

**PEDRO
LENZA**

19^a
EDIÇÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL

ESQUE MATI ZADO[®]

2015

100 ANOS
Saraiva

DE ACORDO COM:

- ✓ **NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL**
- ✓ **EC 88/2015**

INCLUINDO:

- ✓ **ÚLTIMAS
DECISÕES DO STF**
- ✓ **53 SÚMULAS
VINCULANTES**

ISBN 978850262752-9

Lenza, Pedro

Direito constitucional esquematizado® / Pedro Lenza. – 19. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2015.

1. Direito constitucional I. Título.

15-05774 CDU-342

Índices para catálogo sistemático:

1. Direito constitucional 342

Diretor editorial Luiz Roberto Curia

Gerente editorial Thaís de Camargo Rodrigues

Assistente editorial Deborah Caetano de Freitas Viadana

Coordenação geral Clarissa Boraschi Maria

Preparação de originais Maria Izabel Barreiros Bitencourt Bressan e Ana

Cristina Garcia (coords.) |

Arte, diagramação e revisão Know-how Editorial

Conversão para E-pub Guilherme Henrique Martins Salvador

Serviços editoriais Elaine Cristina da Silva | Kelli Priscila Pinto | Tiago

Dela Rosa

Capa Aero Comunicação

Data de fechamento da edição: 25-6-2015

Dúvidas?

Acesse www.editorasaraiva.com.br/direito

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.



SUMÁRIO

Uma homenagem especial

Mais uma homenagem especial

Uma nova homenagem especial

Mais uma nova homenagem especial

Agradecimentos

Nota do autor à 19.^a edição

Prefácio

Apresentação à 1.^a edição

1 - (NEO)Constitucionalismo

1.1. Alocação do Direito Constitucional

1.1.1. A classificação em “ramos do direito”

1.1.2. A superação da dicotomia “público-privado” —
constitucionalização do direito privado

1.2. Constitucionalismo

1.2.1. Conceito

1.2.2. Evolução histórica

1.2.2.1. Constitucionalismo durante a Antiguidade

1.2.2.2. Constitucionalismo durante a Idade Média

- 1.2.2.3. Constitucionalismo durante a Idade Moderna
- 1.2.2.4. Constitucionalismo norte-americano
- 1.2.2.5. Constitucionalismo moderno (durante a Idade Contemporânea)
- 1.2.2.6. Constitucionalismo contemporâneo (durante a Idade Contemporânea) “antenado” com a ideia de “constitucionalismo globalizado”
- 1.2.2.7. Constitucionalismo do futuro: o que podemos esperar?

1.2.3. Esquematização do constitucionalismo

1.3. NEOCONSTITUCIONALISMO

1.3.1. Aspectos iniciais

1.3.2. Pontos marcantes do neoconstitucionalismo

1.3.3. Marcos fundamentais para se chegar a um “novo direito constitucional” (neoconstitucionalismo)

1.4. O novo constitucionalismo democrático latino-americano. Constitucionalismo pluralista (andino ou indígena). Estado plurinacional e intercultural

1.5. Constitucionalismo E SOBERANIA POPULAR

1.5.1. Aspectos gerais

1.6. Questões

2 - CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, CLASSIFICAÇÕES, ELEMENTOS E HISTÓRICO

2.1. Conceito

2.1.1. Sentido sociológico

2.1.2. Sentido político

2.1.3. Sentido material e formal

2.1.4. Sentido jurídico

2.1.5. Sentido culturalista

2.1.6. Constituição aberta

2.1.7. Concepções da Constituição: qual o seu papel no ordenamento jurídico de um país?

2.1.7.1. Constituição-lei

2.1.7.2. Constituição-fundamento (Constituição-total)

2.1.7.3. Constituição-moldura

2.1.7.4. Constituição dúctil (Constituição maleável, suave) (“Costituzione mite” — Gustavo Zagrebelsky)

2.2. Crowdsourced constitution: o legado da experiência pioneira da Islândia (2011)¹⁸

2.3. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA²⁴

2.3.1. Aspectos iniciais

2.3.2. Legislação simbólica

2.3.2.1. Confirmação de valores sociais

2.3.2.2. Demonstração da capacidade de ação do Estado no tocante à solução dos problemas sociais (legislação-álibi)

2.3.2.3. Adiamento da solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios

2.3.2.4. Efeitos sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica

2.3.3. Constitucionalização simbólica

2.3.4. Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico

2.3.5. Neoconstitucionalismo, ativismo judicial e a concretização das normas constitucionais

2.4. Classificação (tipologia)

2.4.1. Quanto à origem e a distinção entre “Constituição” e “Carta”

2.4.2. Quanto à forma

2.4.3. Quanto à extensão

2.4.4. Quanto ao conteúdo

- 2.4.5. Quanto ao modo de elaboração
- 2.4.6. Quanto à alterabilidade
- 2.4.7. Quanto à sistemática (critério sistemático)
- 2.4.8. Quanto à dogmática
- 2.4.9. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência)
- 2.4.10. Quanto ao sistema
- 2.4.11. Quanto à função
- 2.4.12. Quanto à origem de sua decretação: heterônomas (heteroconstituições) x autônomas (“autoconstituições” ou “homoconstituições”)
- 2.4.13. Constituições garantia, balanço e dirigente (Manoel Gonçalves Ferreira Filho)
- 2.4.14. Constituições liberais (negativas) e sociais (dirigentes) — conteúdo ideológico das Constituições (André Ramos Tavares)
- 2.4.15. Raul Machado Horta (Constituições expansivas)
- 2.4.16. A Constituição Federal brasileira de 1988
- 2.5. Elementos das Constituições
- 2.6. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS⁸²
 - 2.6.1. Constituição de 1824
 - 2.6.2. Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo Provisório da República
 - 2.6.3. Constituição de 1891
 - 2.6.4. A Revolução de 1930 — segundo Governo Provisório da República
 - 2.6.5. Constituição de 1934
 - 2.6.6. Constituição de 1937
 - 2.6.7. Constituição de 1946
 - 2.6.8. Golpe Militar de 1964

2.6.9. Constituição de 1967

2.6.10. “Constituição” de 1969 — EC n. 1, de 17.10.1969

2.6.11. Constituição de 1988

2.7. Questões

2.7.1. Conceito, classificação e elementos das Constituições

2.7.2. Histórico das Constituições brasileiras

3 - HERMENÊUTICA: MUTAÇÃO X REFORMA. REGRAS X PRINCÍPIOS. “DERROTABILIDADE”. POSTULADOS NORMATIVOS. CRIAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO

3.1. Mutações constitucionais versus reformas constitucionais

3.2. Regras e princípios

3.3. DERROTABILIDADE (defeasibility)¹⁸

3.4. NORMAS DE SEGUNDO GRAU: POSTULADOS NORMATIVOS

3.5. Métodos de interpretação

3.5.1. Método jurídico ou hermenêutico clássico

3.5.2. Método tópico-problemático (ou método da tópica)

3.5.3. Método hermenêutico-concretizador

3.5.4. Método científico-espiritual

3.5.5. Método normativo-estruturante

3.5.6. Método da comparação constitucional

3.6. princípios da interpretação constitucional

3.6.1. Princípio da unidade da Constituição

3.6.2. Princípio do efeito integrador

3.6.3. Princípio da máxima efetividade

3.6.4. Princípio da justeza ou da conformidade (exatidão ou correção) funcional

3.6.5. Princípio da concordância prática ou harmonização

3.6.6. Princípio da força normativa

- 3.6.7. Princípio da interpretação conforme a Constituição
- 3.6.8. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade
- 3.7. limites da interpretação constitucional
 - 3.7.1. Decisões interpretativas em sentido estrito
 - 3.7.1.1. Sentença interpretativa de rechaço
 - 3.7.1.2. Sentença interpretativa de aceitação
 - 3.7.2. Decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)
 - 3.7.2.1. Sentenças aditivas (ou sentenças manipulativas de efeito aditivo). Declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo ou aditivo
 - 3.7.2.2. Sentenças substitutivas (declaração de inconstitucionalidade com efeito substitutivo)
 - 3.7.3. Lacuna constitucional e o “pensamento jurídico do possível” na jurisprudência do STF
 - 3.7.4. Críticas ao “pan-principiologismo” e a realidade de uma inegável “Supremocracia”
- 3.8. teoria dos poderes implícitos
- 3.9. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição
- 3.10. Estrutura da constituição65
 - 3.10.1. Preâmbulo
 - 3.10.1.1. Esquematização
 - 3.10.1.2. Qual a natureza jurídica do preâmbulo? Tem ele relevância jurídica?
 - 3.10.1.3. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios? Referida previsão enfraquece a laicidade do Estado brasileiro?

3.10.2. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)

3.10.2.1. Apontamentos gerais sobre o ADCT

3.10.2.2. Finalidade do ADCT

3.10.2.3. Classificação das disposições do ADCT

3.10.2.4. O natural exaurimento das normas do ADCT e o seu desvirtuamento

3.10.2.5. Qual a natureza jurídica das disposições do ADCT?

3.10.2.6. As disposições do ADCT estão imunes ao poder de reforma?

3.11. Questões

3.11.1. Hermenêutica

3.11.2. Estrutura da Constituição

4 - PODER CONSTITUINTE

4.1. Esquema geral

4.2. Conceito e titularidade

4.3. HIATO CONSTITUCIONAL (REVOLUÇÃO — MUTAÇÃO — REFORMA — HIATO AUTORITÁRIO)

4.4. Poder constituinte originário (GENUÍNO OU DE 1.º GRAU)

4.4.1. Conceito

4.4.2. Uma subdivisão

4.4.3. Características

4.4.4. Poder constituinte originário formal e material

4.4.5. Formas de expressão

4.4.6. A proposta de convocação de uma “assembleia nacional constituinte exclusiva e específica” para a reforma política: aberração jurídica; violência ao sistema

4.5. Poder constituinte derivado (instituído, constituído, secundário, de 2.º grau ou remanescente)

- 4.5.1. Conceito e espécies¹³
- 4.5.2. Poder constituinte derivado reformador
- 4.5.3. Poder constituinte derivado decorrente
 - 4.5.3.1. Estados-Membros
 - 4.5.3.2. Distrito Federal
 - 4.5.3.3. Municípios: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?
 - 4.5.3.4. Territórios Federais: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?
- 4.5.4. Poder constituinte derivado revisor
- 4.6. PODER CONSTITUINTE DIFUSO
- 4.7. PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL
- 4.8. Nova Constituição e ordem jurídica anterior
 - 4.8.1. Recepção
 - 4.8.1.1. Inconstitucionalidade superveniente?
 - 4.8.1.2. Uma lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada, mas que, até o advento da nova Constituição, nunca fora objeto de controle de constitucionalidade, poderá ser recebida pela nova Constituição se com ela for compatível?
 - 4.8.1.3. Características conclusivas sobre o fenômeno da recepção
 - 4.8.2. Repristinação
 - 4.8.3. Desconstitucionalização
 - 4.8.4. Recepção material de normas constitucionais
- 4.9. poder constituinte e direito adquirido. GRAUS DE RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL: máximo, médio ou mínimo?
- 4.10. Questões
 - 4.10.1. Poder constituinte

4.10.2. Nova Constituição e ordem jurídica anterior

4.10.3. Graus de retroatividade da norma constitucional

5 - EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

5.1. Eficácia jurídica e eficácia social

5.2. Normas constitucionais de eficácia plena

5.3. Normas constitucionais de eficácia contida

5.4. Normas constitucionais de eficácia limitada

5.5. A classificação de Maria Helena Diniz

5.6. A classificação de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto

5.7. Normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada

5.8. Normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais e o gradualismo eficaz das normas constitucionais

5.9. EFICÁCIA E APLICABILIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO STF

5.10. Questões

6 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

6.1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: DIREITO COMPARADO E SISTEMA BRASILEIRO¹

6.1.1. Noções preliminares

6.1.2. A inconstitucionalidade das leis e a regra geral da “teoria da nulidade”. Sistema austríaco (Kelsen) versus Sistema norte-americano (Marshall). Anulabilidade versus nulidade

6.1.3. Flexibilização das teorias da “nulidade absoluta da lei declarada inconstitucional” e da “anulabilidade da norma inconstitucional” no direito estrangeiro (brevíssima noção)

6.1.3.1. Áustria

6.1.3.2. Estados Unidos

6.1.3.3. Espanha

6.1.3.4. Portugal

6.1.3.5. Alemanha

6.1.4. Flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro

6.1.4.1. A mitigação do princípio da nulidade no controle concentrado — art. 27 da Lei n. 9.868/99 e art. 11 da Lei n. 9.882/99

6.1.4.2. A mitigação do princípio da nulidade no controle difuso

6.2. BREVE ANÁLISE EVOLUTIVA DO SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE²⁷

6.2.1. Constituição de 1824

6.2.2. Constituição de 1891

6.2.3. Constituição de 1934

6.2.4. Constituição de 1937

6.2.5. Constituição de 1946

6.2.6. Constituição de 1967 e EC n. 1/69

6.2.7. Constituição de 1988

6.3. ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE

6.3.1. Inconstitucionalidade por ação e por omissão (quadro esquemático)

6.3.2. Vício formal (inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato)

6.3.2.1. Inconstitucionalidade formal orgânica

6.3.2.2. Inconstitucionalidade formal propriamente dita

6.3.2.3. Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo

6.3.3. Vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário)

6.3.4. Vício de decoro parlamentar (?)

6.4. MOMENTOS DE CONTROLE

6.4.1. Controle prévio ou preventivo

6.4.1.1. Controle prévio ou preventivo realizado pelo legislativo

6.4.1.2. Controle prévio ou preventivo realizado pelo executivo

6.4.1.3. Controle prévio ou preventivo realizado pelo judiciário

6.4.1.4. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder judiciário e a perspectiva das “normas constitucionais interpostas” (Zagrebel'sky)

6.4.2. Controle posterior ou repressivo

6.4.2.1. Controle político

6.4.2.2. Controle jurisdicional

6.4.2.3. Controle híbrido

6.4.2.4. Exceção à regra geral do controle jurisdicional posterior ou repressivo

6.4.2.4.1. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Legislativo

6.4.2.4.2. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Executivo

6.4.2.4.3. Controle posterior ou repressivo exercido pelo TCU

6.5. SISTEMAS E VIAS DE CONTROLE JUDICIAL

6.6. CONTROLE DIFUSO

6.6.1. Origem histórica: Marbury versus Madison, Sessão de fev. de 1803 (I, repertório de Cranch, 137-180)

6.6.2. Noções gerais

6.6.3. Controle difuso nos tribunais e a cláusula de reserva de plenário (full bench). Art. 97 da CF/88

6.6.3.1. Regras gerais

6.6.3.2. A cláusula de reserva de plenário se aplica às Turmas do STF no julgamento de RE?

6.6.3.3. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais?

6.6.3.4. A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão de juízo monocrático de primeira instância?

6.6.4. Efeitos da decisão

6.6.4.1. Para as partes

6.6.4.2. Para terceiros (art. 52, X)

6.6.4.2.1. Procedimento

6.6.4.2.2. Amplitude do art. 52, X

6.6.4.2.3. A expressão “no todo ou em parte”

6.6.4.2.4. Efeitos propriamente ditos

6.6.4.2.5. O Senado é obrigado a suspender os efeitos?

6.6.5. Teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso: análise crítica — abstrativização do controle difuso? — tendência para uma maior expansividade das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias individuais. Limitação do cabimento da reclamação.⁸⁵ Perspectivas do controle incidental em controle concentrado

6.6.5.1. Abstrativização do controle difuso?

6.6.5.2. Eficácia expansiva das decisões. Objetivação do recurso extraordinário. Limites à reclamação constitucional. Inconstitucionalidades no CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)

6.6.5.3. Controle incidental em controle concentrado abstrato e o seu efeito “erga omnes” — eficácia da decisão do STF

6.6.6. Controle difuso em sede de ação civil pública

6.7. CONTROLE CONCENTRADO¹⁰⁹

6.7.1. ADI genérica

6.7.1.1. Conceito (ADI genérica)

6.7.1.2. Objeto (ADI genérica)

6.7.1.2.1. Leis

6.7.1.2.2. Atos normativos

6.7.1.2.3. Súmulas?

6.7.1.2.4. Emendas constitucionais?

6.7.1.2.5. Medidas provisórias?

6.7.1.2.6. Regulamentos subordinados ou de execução e decretos? Inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua

6.7.1.2.7. Tratados internacionais

6.7.1.2.8. Normas constitucionais originárias

6.7.1.2.9. O fenômeno da recepção

6.7.1.2.10. Atos estatais de efeitos concretos e atos estatais de efeitos concretos editados sob a forma de lei (exclusivamente formal)

6.7.1.2.11. Ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida

6.7.1.2.12. Lei revogada ou que tenha perdido a sua vigência após a propositura da ADI. O caso particular da fraude processual. Novas perspectivas: singularidades do caso (não prejudicialidade)

6.7.1.2.13. Alteração do parâmetro constitucional invocado. Novo precedente na linha de não ocorrência de prejuízo desde que analisada a situação concreta. Superação da jurisprudência da Corte

acerca da matéria na hipótese de inadmitida constitucionalidade superveniente

6.7.1.2.14. Divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo

6.7.1.2.15. Respostas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral

6.7.1.2.16. Leis orçamentárias?

6.7.1.2.17. Resoluções do CNJ e do CNMP

6.7.1.2.18. Ato administrativo normativo genérico (ADI 3.202 — agravo regimental em processo administrativo)

6.7.1.2.19. ADI “versus” políticas públicas? A teoria da “reserva do possível”

6.7.1.3. Elementos essenciais do controle de constitucionalidade: a) elemento conceitual (o conceito de “bloco de constitucionalidade”); b) elemento temporal

6.7.1.4. Teoria da transcendência dos motivos determinantes (efeitos irradiantes ou transbordantes?) (“Ratio decidendi” — “holding” versus “obiter dictum” — “dictum”)

6.7.1.5. Teoria da inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”, ou inconstitucionalidade consequencial, ou inconstitucionalidade consequente ou derivada, ou “inconstitucionalidade por reverberação normativa”

6.7.1.6. Lei “ainda constitucional”, ou “inconstitucionalidade progressiva”, ou “declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade”

6.7.1.6.1. A instituição da Defensoria Pública pela CF/88 e a sua potencialização pela EC n. 80/2014

6.7.1.6.1.1. A questão do “prazo em dobro”

para a Defensoria Pública no processo penal — rejeição de inconstitucionalidade “rebus sic stantibus”

6.7.1.6.1.2. Ação civil “ex delicto” ajuizada pelo MP — art. 68 do CPP (lei ainda constitucional e em trânsito para revogação por não recepção)

6.7.1.6.2. Procedimento de aprovação das medidas provisórias: apreciação pela comissão mista nos termos do art. 62, § 9.º, da CF/88. Arts. 5.º, “caput”, e 6.º, “caput”, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN

6.7.1.7. “Inconstitucionalidade circunstancial”

6.7.1.8. O efeito vinculante para o Legislativo e o inconcebível fenômeno da “fossilização da Constituição”

6.7.1.9. Município putativo. Princípio da reserva do impossível. Princípio da continuidade do Estado. Princípio federativo. Princípio da segurança jurídica. Princípio da confiança (Karl Larenz). Princípio da força normativa dos fatos (Georg Jellinek). Princípio da situação excepcional consolidada — ADI 2.240/BA — voto do Min. Eros Grau. Voto do Min. Gilmar Mendes — Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Efeito prospectivo. Possibilidade inédita do fenômeno da constitucionalidade superveniente. Dogma da nulidade da lei e garantia da segurança jurídica

6.7.1.10. “Princípio” da proibição do “atalhamento constitucional” e do “desvio de poder constituinte” (utilização de meio aparentemente legal buscando atingir finalidade ilícita)

6.7.1.11. Inconstitucionalidade “chapada”, “enlouquecida”, “desvairada”

6.7.1.12. Início da eficácia da decisão que reconhece a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de lei em processo objetivo de controle abstrato

6.7.1.13. Competência (ADI genérica)

6.7.1.13.1. Lei ou ato normativo federal ou estadual em face da CF

6.7.1.13.2. Lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da CE

6.7.1.13.3. Lei ou ato normativo municipal em face da CF

6.7.1.13.4. Lei ou ato normativo distrital em face da CF/88

6.7.1.13.5. Lei ou ato normativo distrital em face da Lei Orgânica Distrital

6.7.1.13.6. Lei municipal em face da lei orgânica do Município

6.7.1.14. Legitimidade (ADI genérica)

6.7.1.15. Procedimento e características marcantes do processo objetivo (ADI genérica)

6.7.1.16. A figura do “amicus curiae” (ADI e demais ações)

6.7.1.16.1. Regras gerais

6.7.1.16.2. É possível a admissão do “amicus curiae” na ADC?

6.7.1.16.3. Cabe “amicus curiae” na ADPF?

6.7.1.16.4. Cabe “amicus curiae” na ADO?

6.7.1.16.5. Cabe “amicus curiae” na IF (representação interventiva)?

6.7.1.16.6. Outras hipóteses de cabimento

6.7.1.16.7. Parlamentar pode ser admitido no processo como “amicus curiae”? (Novidade mais ampla introduzida pelo CPC/2015 — Lei n. 13.105/2015)

6.7.1.16.8. Natureza jurídica do “amicus curiae”

6.7.1.16.9. “Amicus curiae” pode interpor recurso? Particularidades do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)

6.7.1.17. Efeitos da decisão (ADI genérica)

6.7.1.17.1. Princípio da parcelaridade

6.7.1.17.2. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto

6.7.1.17.3. Efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Necessidade de impugnação de todo o “complexo normativo”

6.7.1.17.4. Efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade¹⁹²

6.7.1.17.4.1. Coisa julgada inconstitucional. S. 343/STF. Rescisória (art. 485, V, CPC/73)

6.7.1.17.4.2. Explicitação da amplitude da S. 343/STF. “Leading Case”: RE 590.809 (j. 22.10.2014). CPC/73 e CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)

6.7.1.17.4.3. Arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73: “embargos rescisórios”. Como ficou no Novo CPC/2015 (arts. 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5.º a 8.º)?

6.7.1.17.4.4. Aspectos conclusivos: efeito da decisão no plano normativo (“Normebene”) e no plano do ato singular (“Einzelaktebene”) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão (interessante tendência apontada pelo Min. Gilmar Mendes). Perspectiva introduzida pelo CPC/2015

6.7.1.17.5. Pedido de cautelar (ADI genérica)

6.7.1.18. Reclamação para a garantia da autoridade da decisão do STF: paradigma de ordem objetiva (ADI genérica e súmula vinculante)

6.7.1.18.1. Regras gerais

6.7.1.18.2. Natureza jurídica do instituto da reclamação

6.7.2. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

6.7.2.1. Conceito (ADC)

6.7.2.2. Objeto (ADC)

6.7.2.3. Competência (ADC)

6.7.2.4. Legitimidade (ADC)

6.7.2.5. Procedimento (ADC)

6.7.2.6. Efeitos da decisão (ADC)

6.7.2.7. Medida cautelar (ADC)

6.7.3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)

6.7.3.1. Localização (ADPF)

6.7.3.2. Objeto — hipóteses de cabimento (ADPF)

6.7.3.3. Preceito fundamental — conceito (ADPF)

6.7.3.4. Competência (ADPF)

6.7.3.5. Legitimidade (ADPF)

6.7.3.6. Procedimento (ADPF). Particularidades do princípio da subsidiariedade

6.7.3.7. Efeitos da decisão (ADPF)

6.7.3.8. O parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99 é inconstitucional (arguição incidental)?

6.7.3.9. Pedido de medida liminar (ADPF)

6.7.3.10. ADPF pode ser conhecida como ADI? Se sim, o princípio da fungibilidade teria natureza ambivalente? Ou seja, ADI poderia ser conhecida como ADPF?

6.7.4. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

6.7.4.1. Conceito (ADO)

6.7.4.2. Espécies de omissão

6.7.4.3. Objeto (ADO)

6.7.4.4. Competência (ADO)

6.7.4.5. Legitimidade (ADO)

6.7.4.6. Natureza jurídica dos legitimados (ADO)

6.7.4.7. Procedimento (ADO)

6.7.4.8. Medida cautelar (ADO)

6.7.4.9. Efeitos da decisão (ADO)

6.7.4.10. A atual jurisprudência do STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO?

6.7.5. Representação interventiva (IF)

6.7.5.1. Conceito (IF)

6.7.5.2. Representação interventiva federal (ADI interventiva federal)

6.7.5.2.1. Objeto (IF)

6.7.5.2.2. Princípios sensíveis

6.7.5.2.3. Competência (IF)

6.7.5.2.4. Legitimidade (IF)

6.7.5.2.5. Procedimento (IF)

6.7.5.2.6. Medida liminar (IF)

6.7.5.2.7. Representação interventiva no caso de recusa à execução de lei federal

6.7.5.3. Representação interventiva estadual (ADI interventiva estadual)

6.8. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS ESTADOS-MEMBROS

6.8.1. Regras gerais

6.8.2. Objeto

6.8.3. Competência

6.8.4. Legitimados

6.8.5. Parâmetro de controle

6.8.5.1. Regras gerais

6.8.5.2. A parametricidade das cláusulas constitucionais estaduais, de caráter remissivo, para fins de controle concentrado, no âmbito do TJ local

6.8.5.3. “Simultaneus processus”

6.8.6. A utilização do recurso extraordinário no controle concentrado e em abstrato estadual

6.9. QUADRO COMPARATIVO DO SISTEMA JURISDICIONAL MISTO DE CONTROLE POSTERIOR OU REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

6.10. QUESTÕES

6.10.1. Conceitos gerais

6.10.2. Legitimidade

6.10.3. Procedimento

6.10.4. Efeitos da decisão

6.10.5. Outras questões

7 - DIVISÃO ESPACIAL DO PODER — ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

7.1. Noções preliminares

7.1.1. Elementos integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado

7.1.2. Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado

7.2. Estado unitário

7.2.1. Estado unitário puro

7.2.2. Estado unitário descentralizado administrativamente

7.2.3. Estado unitário descentralizado administrativa e

politicamente

7.3. Federação

7.3.1. Histórico

7.3.2. Tipologias do Federalismo

7.3.2.1. Federalismo por agregação ou por desagregação (segregação)

7.3.2.2. Federalismo dual ou cooperativo

7.3.2.3. Federalismo simétrico ou assimétrico

7.3.2.4. Federalismo orgânico

7.3.2.5. Federalismo de integração

7.3.2.6. Federalismo equilíbrio

7.3.2.7. Federalismo de segundo grau

7.3.3. Características da Federação

7.3.4. Federação brasileira

7.3.4.1. Breve histórico

7.3.4.2. Federação na CF/88 e princípios fundamentais¹⁷

7.3.4.2.1. Composição e sistematização conceitual

7.3.4.2.2. Fundamentos da República Federativa do Brasil

7.3.4.2.3. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil

7.3.4.2.3.1. Art. 3.º, CF/88

7.3.4.2.3.2. As alterações introduzidas pela EC n. 87/2015 em relação ao ICMS no contexto dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil

7.3.4.2.4. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais

7.3.4.2.5. Idioma oficial e símbolos da República Federativa do Brasil

7.3.4.2.6. Vedações constitucionais impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

7.4. União Federal

7.4.1. Capital Federal

7.4.2. Bens da União

7.4.3. Competências da União Federal

7.4.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)

7.4.3.2. Competência legislativa

7.4.3.3. Competência para legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação — discussão em relação à EC n. 85/2015

7.4.3.4. Legislação sobre o meio ambiente e competência municipal. O caso particular da queima da palha da cana-de-açúcar (RE 586.224)

7.4.4. Regiões administrativas ou de desenvolvimento

7.5. Estados-Membros

7.5.1. Formação dos Estados-Membros

7.5.1.1. Regra geral

7.5.1.2. Aspectos específicos e procedimentais

7.5.1.3. E qual deve ser o procedimento no caso de criação de um novo Estado?

7.5.1.4. Fusão

7.5.1.5. Cisão

7.5.1.6. Desmembramento

7.5.2. Bens dos Estados-Membros

7.5.3. Competências dos Estados-Membros

7.5.3.1. Competência não legislativa (administrativa

ou material)

7.5.3.2. Competência legislativa

7.5.4. Exploração dos serviços locais de gás canalizado

7.5.5. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

7.5.5.1. Aspectos gerais

7.5.5.2. Conceito

7.5.5.3. O que aconteceu com as regiões metropolitanas instituídas antes da nova Constituição de 1988?

7.5.5.4. Caráter compulsório da participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

7.5.5.5. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal que deverá ser preservada. Não se admite a simples transferência de competências exclusivamente para o Estado-Membro. A gestão deverá ser compartilhada

7.5.5.6. “Estatuto da Metrópole” — Lei n. 13.089/2015

7.5.5.7. Qual a natureza jurídica das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões criadas por lei complementar estadual?

7.6. Municípios

7.6.1. Formação dos Municípios

7.6.2. Competências dos Municípios

7.6.2.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)

7.6.2.2. Competências legislativas

7.6.2.3. Competência municipal para legislar sobre meio ambiente (RE 586.224)

7.7. Distrito Federal

- 7.7.1. Histórico
- 7.7.2. Distrito Federal como unidade federada
- 7.7.3. Outras características importantes
- 7.7.4. Competências do Distrito Federal
 - 7.7.4.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)
 - 7.7.4.2. Competências legislativas
- 7.8. Territórios Federais
 - 7.8.1. Histórico
 - 7.8.2. Natureza jurídica
 - 7.8.3. Ainda existem territórios no Brasil?
 - 7.8.4. Mas, afinal de contas, o que é Fernando de Noronha?
 - 7.8.5. Apesar de não existirem, podem vir a ser criados novos territórios?
 - 7.8.6. Outras características importantes
- 7.9. MODELOS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
 - 7.9.1. Modelo clássico e modelo moderno
 - 7.9.1.1. Modelo clássico
 - 7.9.1.2. Modelo moderno
 - 7.9.2. Modelo horizontal e modelo vertical
 - 7.9.2.1. Modelo horizontal
 - 7.9.2.2. Modelo vertical
- 7.10. QUADRO ILUSTRATIVO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL — ALGUNS PRECEDENTES DO STF
- 7.11. AMIANTO, TABACO E OUTDOOR⁶⁵
 - 7.11.1. Amianto
 - 7.11.2. Tabaco
 - 7.11.3. Outdoor — “Lei Cidade Limpa”
- 7.12. Intervenção

7.12.1. Intervenção federal

7.12.1.1. Hipóteses de intervenção federal

7.12.1.2. Espécies de intervenção federal

7.12.1.3. Decretação e execução da intervenção federal

7.12.1.4. Controle exercido pelo Congresso Nacional

7.12.1.4.1. Hipóteses em que o controle exercido pelo Congresso Nacional é dispensado

7.12.1.5. Afastamento das autoridades envolvidas

7.12.2. Intervenção estadual

7.12.2.1. Hipóteses de intervenção estadual e intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais

7.12.2.2. Decretação e execução da intervenção estadual

7.12.2.3. Controle exercido pelo legislativo

7.12.2.3.1. Hipóteses em que o controle exercido pela Assembleia Legislativa é dispensado

7.12.2.4. Afastamento das autoridades envolvidas

7.12.2.5. Súmula 637 do STF

7.13. Questões

7.13.1. Federação: aspectos conceituais

7.13.2. Federação: intervenção

7.13.3. Federação: competência

8 - SEPARAÇÃO DE “PODERES” — TEORIA GERAL

8.1. Noções introdutórias

8.1.1. Aristóteles: identificação das funções do Estado

8.1.2. Montesquieu: correspondência entre a divisão funcional

e a divisão orgânica

8.1.3. E qual seria a finalidade da separação dos poderes?

8.2. funções típicas e atípicas

8.3. Impropriedade da expressão “tripartição de Poderes”

8.4. A independência dos Poderes e a indelegabilidade de atribuições

8.5. Questões

9 - PODER LEGISLATIVO

9.1. Estrutura do poder legislativo

9.1.1. Estrutura do Poder Legislativo federal

9.1.2. Estrutura do Poder Legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais

9.1.2.1. Estrutura do Poder Legislativo estadual

9.1.2.2. Estrutura do poder legislativo municipal

9.1.2.3. Estrutura do poder legislativo distrital

9.1.2.4. Estrutura do poder legislativo dos Territórios Federais

9.2. Atribuições do Congresso Nacional

9.3. Câmara dos Deputados

9.3.1. Aspectos fundamentais

9.3.2. Requisitos para a candidatura dos Deputados Federais

9.3.3. Competências privativas da Câmara dos Deputados

9.4. Senado Federal

9.4.1. Aspectos fundamentais

9.4.2. Requisitos para a candidatura dos Senadores

9.4.3. Competências privativas do Senado Federal

9.5. Quadro comparativo e deliberações

9.6. REMUNERAÇÃO DOS PARLAMENTARES

9.6.1. Subsídio mensal

9.6.2. Verba indenizatória: dever de transparência

9.7. Das reuniões

9.7.1. Sessão legislativa ordinária

9.7.2. Hipóteses de convocação extraordinária

9.7.3. Reunião em sessão conjunta

9.7.4. Sessão preparatória e Mesas Diretoras

9.8. Das comissões parlamentares

9.8.1. Comissão temática ou em razão da matéria (permanentes)

9.8.2. Comissão especial ou temporária

9.8.3. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

9.8.3.1. Regras gerais

9.8.3.2. Criação

9.8.3.3. Direito público subjetivo das minorias

9.8.3.4. Objeto

9.8.3.5. Prazo

9.8.3.6. Poderes

9.8.3.7. O princípio da separação de “poderes” e a impossibilidade de a CPI investigar atos de conteúdo jurisdicional

9.8.3.8. Postulado de reserva constitucional de jurisdição

9.8.3.9. Postulado da colegialidade

9.8.3.10. Motivação

9.8.3.11. Conclusões

9.8.3.12. Competência originária do STF

9.8.3.13. A regra da prejudicialidade

9.8.3.14. CPIs estaduais e quebra do sigilo bancário

9.8.3.15. CPIs distritais

9.8.3.16. CPIs municipais

9.8.4. Comissão mista

9.8.5. Comissão representativa

9.9. Imunidades parlamentares

9.9.1. Aspectos introdutórios

9.9.2. Imunidade parlamentar federal

9.9.2.1. Imunidade material ou inviolabilidade parlamentar (art. 53, "caput")

9.9.2.2. Imunidade formal ou processual

9.9.2.2.1. Imunidade formal ou processual para a prisão (art. 53, § 2.º). Perspectivas em razão do julgamento da AP 470 — “mensalão”

9.9.2.2.2. Imunidade formal ou processual para o processo (art. 53, §§ 3.º a 5.º)

9.9.2.3. Prerrogativa de foro (“foro privilegiado”) (art. 53, § 1.º)

9.9.2.3.1. Regra geral para os parlamentares federais — STF. Cessado o mandato parlamentar, por regra (salvo exceção comentada nos itens seguintes), deixa de existir competência originária da Corte para o julgamento de ação penal contra membro do Congresso Nacional

9.9.2.3.2. Renúncia ao mandato. Caso “Gulliver”. “Ciranda dos processos”. “Valsa processual”. Perspectivas de resgate da S. 394/STF (AP 333)

9.9.2.3.3. Renúncia ao mandato. Manutenção da competência do STF. Abuso de direito. Fraude processual inaceitável (AP 396)

9.9.2.3.4. Necessidade de definição de critério objetivo para a caracterização da

hipótese de fraude processual e abuso de direito a manter a competência do STF em caso de renúncia ao mandato. Renúncia abusiva. Renúncia manipulativa. Debate (AP 536)

9.9.2.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento

9.9.2.5. Outras garantias

9.9.2.6. As imunidades parlamentares podem ser renunciadas?

9.9.2.7. As imunidades parlamentares estendem-se aos suplentes?

9.9.3. Parlamentares estaduais

9.9.4. Parlamentares municipais

9.10. Incompatibilidades e impedimentos dos parlamentares federais

9.11. Perda do mandato do Deputado ou Senador

9.11.1. Hipóteses de perda do mandato e suas peculiaridades

9.11.2. Cassação⁴⁷ x extinção do mandato

9.11.3. Votação aberta na hipótese de cassação do mandato: aprovação da “PEC do voto aberto” (EC n. 76/2013). Avanço democrático

9.11.4. A perda do mandato parlamentar em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado e a interpretação fixada pelo STF no julgamento da AP 470 (“mensalão”), bem como da AP 565 (art. 15, III, x art. 55, §§ 2.º e 3.º). O caso concreto da AP 39650

9.11.5. É possível a renúncia do cargo por parlamentar submetido a processo que vise ou possa levá-lo à perda do mandato?

9.12. Hipóteses em que não haverá a perda do mandato do Deputado
OU SENADOR E OUTRAS REGRAS

9.13. Processo legislativo

9.13.1. Considerações introdutórias

9.13.2. Esquema do processo legislativo das leis ordinárias e complementares

9.13.3. Fase de iniciativa

9.13.3.1. Regra geral para a iniciativa

9.13.3.2. Iniciativa concorrente

9.13.3.3. Iniciativa “privativa” (reservada ou exclusiva)

9.13.3.3.1. Iniciativa reservada ao Presidente da República

9.13.3.3.2. Iniciativa reservada aos Governadores dos Estados e do DF e aos Prefeitos — simetria com o modelo federal

9.13.3.3.3. Iniciativa reservada do Judiciário

9.13.3.3.4. Iniciativa reservada aos Tribunais de Contas

9.13.3.3.5. Assuntos exclusivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

9.13.3.3.6. Podemos falar em iniciativa reservada de matéria tributária?

9.13.3.3.7. Iniciativa do processo legislativo de matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos Anuais

9.13.3.3.8. Pode o legitimado exclusivo ser compelido a deflagrar processo legislativo?

9.13.3.3.9. Cabe emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada?

9.13.3.3.10. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas em relação às normas fruto da manifestação do poder constituinte derivado

decorrente?

9.13.3.3.11. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas, enquanto limites, pelo poder constituinte derivado reformador (PEC)?

9.13.3.3.12. Sanção presidencial convalida vício de iniciativa?

9.13.3.4. Iniciativa popular

9.13.3.4.1. Aspectos gerais

9.13.3.4.2. Existe algum exemplo de lei fruto de iniciativa popular?

9.13.3.4.3. Conclusões iniciais

9.13.3.4.4. Iniciativa popular de “PEC”?

9.13.3.4.5. Cabe iniciativa popular de matérias reservadas à iniciativa exclusiva de outros titulares?

9.13.3.4.6. Iniciativa popular e as espécies normativas: esquematização

9.13.3.4.7. Iniciativa popular em âmbito estadual e municipal

9.13.3.5. Iniciativa conjunta: ainda persiste, tendo em vista a Reforma da Previdência (EC n. 41/2003)?

9.13.3.6. Iniciativa para fixação do subsídio dos Ministros do STF — teto do funcionalismo — art. 48, XV, c/c o art. 96, II, “b”

9.13.3.7. Algumas peculiaridades a serem observadas

9.13.3.7.1. Organização do Ministério Público

9.13.3.7.2. Proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67 — princípio da irrepetibilidade)

9.13.3.7.3. Iniciativa parlamentar ou

extraparlamentar

9.13.4. Fase constitutiva

9.13.4.1. Deliberação parlamentar — discussão e votação

9.13.4.1.1. O projeto começa na Câmara ou no Senado?

9.13.4.1.2. Apreciação pelas Comissões

9.13.4.1.3. Processos de votação

9.13.4.1.4. A Casa revisora

9.13.4.1.5. Espécies de emendas

9.13.4.1.6. Algumas outras regras fundamentais

9.13.4.2. Deliberação executiva — sanção e veto

9.13.4.2.1. Sanção

9.13.4.2.2. Regras gerais sobre o veto

9.13.4.2.3. Os vetos devem ser apreciados na ordem cronológica de sua comunicação ao Congresso Nacional? (MS 31.816 — "royalties" do pré-sal)

9.13.4.2.4. Procedimento de apreciação dos vetos presidenciais (Res. n. 1/2015-CN)

9.13.4.2.5. Regras específicas sobre o veto

9.13.5. Fase complementar — promulgação e publicação

9.13.5.1. Promulgação

9.13.5.2. Publicação

9.14. Espécies normativas

9.14.1. Emenda constitucional

9.14.1.1. Limitações formais ou procedimentais (art. 60, I, II, III, e §§ 2.º, 3.º e 5.º)

9.14.1.2. Limitações circunstanciais (art. 60, § 1.º)

- 9.14.1.3. Limitações materiais (art. 60, § 4.º)
- 9.14.1.4. Limitações temporais?
- 9.14.1.5. Limitações implícitas
- 9.14.1.6. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e a sua equivalência com as emendas constitucionais — EC n. 45/2004
- 9.14.2. Lei complementar e lei ordinária
 - 9.14.2.1. Semelhanças
 - 9.14.2.2. Diferenças
 - 9.14.2.2.1. Aspecto material
 - 9.14.2.2.2. Aspecto formal
 - 9.14.2.3. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária?
- 9.14.3. Lei delegada
- 9.14.4. Medida provisória
 - 9.14.4.1. Aspectos iniciais
 - 9.14.4.2. O processo de criação das medidas provisórias de acordo com a EC n. 32/2001
 - 9.14.4.3. Parecer prévio pela comissão mista e a inconstitucionalidade dos arts. 5.º, "caput", e 6.º, "caput", e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN
 - 9.14.4.4. Medidas a serem adotadas pelo Congresso Nacional
 - 9.14.4.4.1. Aprovação sem alteração
 - 9.14.4.4.2. Aprovação com alteração
 - 9.14.4.4.3. Não apreciação (rejeição tácita)
 - 9.14.4.4.4. Rejeição expressa
 - 9.14.4.5. Impacto da medida provisória sobre o ordenamento jurídico
 - 9.14.4.6. Pode o Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória

já editada?

9.14.4.7. Limitação material à edição de medidas provisórias, de acordo com a EC n. 32/2001

9.14.4.8. O que acontecerá com as medidas provisórias editadas em data anterior à EC n. 32/2001?

9.14.4.9. Um alerta

9.14.5. Decreto legislativo

9.14.5.1. Aspectos gerais

9.14.5.2. Breves notas sobre o processo de formação dos tratados internacionais e a novidade trazida pela EC n. 45/2004

9.14.5.2.1. Tratados e convenções internacionais gerais

9.14.5.2.2. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (EC n. 45/2004)

9.14.5.2.3. A “supralegalidade” dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos

9.14.6. Resolução

9.14.7. Quadro comparativo das espécies normativas

9.15. Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e o Tribunal de Contas

9.15.1. Tribunal de Contas da União

9.15.1.1. Composição e características

9.15.1.2. Atribuições constitucionais do TCU

9.15.1.3. “Apreciar as contas” x “julgar as contas” (art. 71, I e II)

9.15.1.4. Exercício do controle difuso de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas

9.15.1.5. Sustação de “atos” e “contratos”

administrativos pelo Tribunal de Contas

9.15.1.6. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas?

9.15.1.7. É necessária a observância do devido processo legal em processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas?

9.15.1.8. O Tribunal de Contas pode exigir, por si, a quebra de sigilo bancário?

9.15.1.9. Teoria dos poderes implícitos e as atribuições do Tribunal de Contas — possibilidade de concessão de medidas cautelares para assegurar o exercício de suas atribuições

9.15.1.10. Situação jurídica acobertada pela autoridade da coisa julgada pode ser desconstituída por decisão ou ato do Tribunal de Contas?

9.15.1.11. Decisões do Tribunal de Contas com eficácia de título executivo

9.15.1.12. Ao decidir, cabe ao Tribunal de Contas manter o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia?

9.15.1.13. Ministros do Tribunal de Contas da União

9.15.2. Distinção entre a atuação do TCU e da CGU: inexistência de invasão de atribuições. Auxílio no controle externo (TCU) x controle interno (CGU) — perfeita convivência

9.15.3. Tribunais de Contas Estaduais e Tribunal de Contas do Distrito Federal

9.15.4. Tribunais de Contas Municipais

9.15.5. Ministério Público Especial (art. 130)

9.16. Questões

9.16.1. Do Poder Legislativo — Aspectos gerais (estrutura, atribuições, reuniões, comissões, imunidades, incompatibilidades e impedimentos, perda do mandato)

- 9.16.2. Tribunal de Contas
- 9.16.3. Processo legislativo
- 9.16.4. Espécies normativas

10 - PODER EXECUTIVO

- 10.1. Notas introdutórias
- 10.2. Presidencialismo versus parlamentarismo
- 10.3. Executivo monocrático, colegial, diretorial e dual — conceito
- 10.4. O poder executivo na CF/88
 - 10.4.1. O exercício do Poder Executivo no Brasil
 - 10.4.1.1. Âmbito federal
 - 10.4.1.2. Âmbito estadual
 - 10.4.1.3. Âmbito distrital
 - 10.4.1.4. Âmbito municipal
 - 10.4.1.5. Âmbito dos Territórios Federais
 - 10.4.2. Atribuições conferidas ao Presidente da República
 - 10.4.2.1. Regras gerais do art. 84 da CF/88
 - 10.4.2.2. Regras específicas decorrentes do art. 84 da CF/88
 - 10.4.2.3. O poder regulamentar e a realidade dos denominados “decretos autônomos”
 - 10.4.3. Condições de elegibilidade
 - 10.4.4. Processo eleitoral
 - 10.4.5. Posse e mandato
 - 10.4.6. Impedimento e vacância dos cargos
 - 10.4.6.1. Sucessor e substituto natural do Presidente da República: Vice-Presidente
 - 10.4.6.2. Substitutos eventuais ou legais
 - 10.4.6.3. Mandato-tampão: eleição direta e indireta (art. 81)

10.4.6.4. Ausência do País do Presidente e do Vice-Presidente da República e licença do Congresso Nacional

10.4.7. Ministros de Estado

10.4.7.1. Características gerais e requisitos de investidura no cargo

10.4.7.2. Atribuições dos Ministros de Estado

10.4.7.3. Poderão os Ministros de Estado receber delegação para exercer matéria de competência privativa do Presidente da República?

10.4.7.4. Responsabilidade e juízo competente para processar e julgar os Ministros de Estado. A análise do controle político pela Câmara dos Deputados (art. 51, I)

10.4.8. Conselho da República

10.4.9. Conselho de Defesa Nacional

10.4.10. Crimes de responsabilidade

10.4.10.1. Notas introdutórias e natureza jurídica

10.4.10.2. Procedimento

10.4.10.2.1. Câmara dos Deputados

10.4.10.2.2. Senado Federal

10.4.10.3. Controle judicial?

10.4.11. Crimes comuns

10.4.11.1. Conceito e procedimento

10.4.11.2. Imunidade presidencial (irresponsabilidade penal relativa)

10.4.12. Prisão

10.4.13. A imunidade formal relativa à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa podem ser estendidas aos demais chefes do Poder Executivo por leis dos respectivos entes federativos?

10.4.14. Outras regras importantes sobre os demais Chefes do

Poder Executivo

10.4.14.1. Os demais entes federativos podem dispor sobre crime de responsabilidade definindo o órgão julgador por ato legislativo próprio?

10.4.14.2. Os demais entes federativos podem estabelecer a licença prévia pelo legislativo local para o julgamento dos Chefes do Executivo?

10.4.15. Sistematização da competência para julgamento das autoridades pela prática de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade

10.4.15.1. Prefeitos Municipais

10.4.15.2. Vereadores Municipais

10.4.15.3. A inconstitucionalidade das regras trazidas pela Lei n. 10.628/2002 em relação à “perpetuatio jurisdictionis” e ao “inusitado foro cível por prerrogativa de função em lei processual penal”

10.4.15.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento

10.4.15.5. Distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na CF — Rcl 2.138-6-DF

10.4.15.6. Responsabilidade fiscal e as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas — LC n. 101/2000 e Lei n. 10.028/2000

10.5. Questões

11 - PODER JUDICIÁRIO

11.1. FUNÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO

11.2. Algumas características da jurisdição

11.3. Reforma do Poder Judiciário — EC n. 45/20047

11.3.1. Histórico de sua tramitação

11.3.2. Principais alterações

- 11.3.3. Principais ações diretas e decisões do STF em relação às novidades introduzidas pela EC n. 45/2004 (ordem cronológica de propositura)
- 11.4. Estatuto da Magistratura
 - 11.4.1. Disposições gerais
 - 11.4.2. EC n. 88/2015 e ADI 5.316 (“PEC da Bengala”)
- 11.5. Garantias do Judiciário
 - 11.5.1. Garantias institucionais do Judiciário
 - 11.5.1.1. Garantias de autonomia orgânico-administrativa
 - 11.5.1.2. Garantias de autonomia financeira
 - 11.5.2. Garantias funcionais do Judiciário (ou de órgãos)
 - 11.5.2.1. Garantias de independência dos órgãos judiciários
 - 11.5.2.1.1. Vitaliciedade
 - 11.5.2.1.2. Inamovibilidade
 - 11.5.2.1.3. Irredutibilidade de subsídios
 - 11.5.2.2. Garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários
 - 11.5.3. Prerrogativa de foro: o magistrado aposentado tem direito a foro especial por prerrogativa de função?
- 11.6. Estrutura do Judiciário
 - 11.6.1. Órgãos de convergência e órgãos de superposição
 - 11.6.2. Justiças: comum e especial
 - 11.6.3. Competência penal versus competência civil
 - 11.6.4. Juizados Especiais: algumas particularidades
 - 11.6.4.1. Não cabimento de Recurso Especial para o STJ e o cabimento de Rcl
 - 11.6.4.2. Cabimento de RE para o STF
 - 11.6.4.3. Cabimento de HC e MS contra ato de juizado

especial — superação da S. 690/STF

11.6.4.4. Ação de indenização em razão do fumo: incompetência dos Juizados — complexidade da causa

11.6.4.5. Juizados e a Lei Maria da Penha

11.6.5. Organograma do Poder Judiciário⁴⁴

11.7. A REGRA DO “QUINTO CONSTITUCIONAL”

11.8. Características gerais dos órgãos do Poder Judiciário

11.8.1. Supremo Tribunal Federal (STF)

11.8.1.1. STF — aspectos históricos⁵²

11.8.1.2. STF — regras gerais

11.8.1.3. STF — destaques às novidades trazidas pela EC n. 45/2004 (“Reforma do Judiciário”)

11.8.1.4. STF — procedimento para deliberação e encaminhamento de solicitações de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPR)

11.8.2. Superior Tribunal de Justiça (STJ)

11.8.3. Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Juízes Federais

11.8.4. Tribunais e Juízes do Trabalho de acordo com a EC n. 24/99

11.8.4.1. Tribunal Superior do Trabalho (TST)

11.8.4.2. Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs)

11.8.4.3. Juízes do trabalho — Varas do Trabalho

11.8.4.4. Competências da Justiça do Trabalho

11.8.4.5. O que aconteceu com os mandatos dos classistas em face da EC n. 24/99?

11.8.5. Tribunais e Juízes Eleitorais

11.8.5.1. Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

11.8.5.2. Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

- 11.8.5.3. Juízes Eleitorais
- 11.8.5.4. Juntas Eleitorais
- 11.8.6. Tribunais e Juízes Militares
 - 11.8.6.1. Superior Tribunal Militar (STM)
 - 11.8.6.2. Justiça Militar da União
 - 11.8.6.2.1. Regras gerais e Circunscrições Judiciárias Militares
 - 11.8.6.2.2. Conselhos de Justiça Militar
 - 11.8.6.2.3. Hierarquia militar (postos e graduações)
 - 11.8.6.2.4. Ministério Público Militar e Defensoria Pública da União^{74 75}
 - 11.8.6.2.5. A Justiça Militar da União julga civil?
 - 11.8.6.2.6. E os crimes dolosos contra a vida?
 - 11.8.6.2.7. A Lei n. 9.099/95 (que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências) se aplica no âmbito da Justiça Militar?
 - 11.8.6.2.8. A Justiça Militar da União e a Reforma do Judiciário
 - 11.8.6.3. Justiça Militar dos Estados
 - 11.8.6.3.1. Atribuições
 - 11.8.6.3.2. Composição e competência
 - 11.8.6.3.3. Aplicação da pena de perda do posto e da patente (oficiais) e da graduação (praças): atribuição exclusiva do Tribunal competente ou possibilidade de ser imposta como pena acessória?
 - 11.8.6.3.4. Hierarquia militar estadual (postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar)⁸⁵

11.8.6.3.5. Ministério Público Estadual e
Defensoria Pública Estadual (Justiça
Militar Estadual)

11.8.6.4. Justiça Militar do Distrito Federal

11.8.7. Tribunais e Juízes dos Estados

11.8.8. Varas Agrárias e os conflitos fundiários

11.8.9. Justiça Estadual é competente para julgar crimes
comuns entre silvícolas

11.8.10. Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios

11.9. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONVOCAÇÃO DE
JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU PARA COMPOR ÓRGÃO
JULGADOR DE TRIBUNAL

11.10. mAGISTRATURA — teto de subsídio x teto de remuneração —
PODER JUDICIÁRIO — caráter nacional E UNITÁRIO

11.11. Da Justiça de Paz (art. 98, II)

11.11.1. Regras gerais

11.11.2. Os juízes de paz integram o Poder Judiciário?

11.12. Dos precatórios

11.12.1. Regras gerais

11.12.2. Espécies de precatórios e exceção no caso das
obrigações de pequeno valor

11.12.3. Sistemática da “superpreferência” — art. 100, § 2.º
(EC n. 62/2009)

11.12.4. Compensação de precatório com débitos tributários
— inconstitucionalidade reconhecida pelo STF

11.12.5. Utilização de precatórios para compra de imóveis
públicos

11.12.6. Atualização de valores de requisitórios de acordo
com os índices da caderneta de poupança —
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF

11.12.7. Cessão dos créditos em precatórios a terceiros e a
possibilidade de assunção de débitos diretamente pela União

11.12.8. Regime especial para pagamento de crédito de precatórios — art. 100, § 15, da CF/88 e art. 97 do ADCT — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Modulação dos efeitos da decisão — sobrevida ao regime especial por 5 exercícios financeiros a contar de 1.º.01.2016 (ADIs 4.357 e 4.425-QO, j. 25.03.2015)

11.12.9. Regime especial para pagamento de crédito de precatórios e os parcelamentos anteriores introduzidos pelos arts. 33 e 78 do ADCT

11.12.10. Débitos das entidades da administração indireta: precatórios?

11.12.11. Intervenção federal ou estadual e não pagamento de precatórios

11.13. Conselho Nacional de Justiça

11.13.1. Aspectos gerais e composição do CNJ

11.13.2. Aperfeiçoamento do CNJ: EC n. 61/2009

11.13.3. Inexistência de regulamentação (critérios objetivos) para a indicação dos membros do CNJ

11.13.4. O CNJ é constitucional?

11.13.5. Atribuições do CNJ e o controle de suas decisões pelo STF (limites?)

11.13.5.1. Regras gerais

11.13.5.2. O CNJ não exerce função jurisdicional

11.13.5.3. O CNJ tem atribuição para exercer o controle de constitucionalidade?

11.13.5.4. STF: órgão de cúpula jurisdicional e órgão de cúpula administrativa, financeira e disciplinar (amplitude)

11.13.5.5. O STF não deve ser considerado mera instância ordinária revisora das decisões administrativas do CNJ

11.13.6. O CNJ tem controle da função jurisdicional do Judiciário?

11.13.7. Corregedoria Nacional de Justiça e Ministro-Corregedor do CNJ

11.13.8. O CNJ, no exercício de suas atribuições correccionais, atua originariamente (primariamente) e concorrentemente com as Corregedorias dos tribunais

11.13.9. Prerrogativa de foro

11.13.10. Outras regras sobre o CNJ

11.14. Súmula vinculante

11.14.1. Duas realidades: a morosidade da Justiça e as teses jurídicas repetitivas

11.14.2. As “famílias” do direito

11.14.3. Influência do stare decisis da família da common law

11.14.4. Influência da Alemanha e da Áustria

11.14.5. A influência do direito português

11.14.6. A evolução do “direito sumular” no Brasil (fase colonial — influência do direito português)

11.14.7. A evolução do “direito sumular” no Brasil (após a independência)

11.14.8. Prenúncios da súmula vinculante em âmbito constitucional

11.14.9. Prenúncios da súmula vinculante no âmbito do direito processual civil

11.14.10. Os contornos da súmula vinculante na EC n. 45/2004

11.14.11. As regras trazidas pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006 — súmula vinculante

11.14.11.1. Competência

11.14.11.2. Objeto

11.14.11.3. Requisitos para a edição

11.14.11.4. Legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante

11.14.11.5. Procedimento

- 11.14.11.6. Efeitos da súmula
- 11.14.11.7. Modulação dos efeitos
- 11.14.11.8. Revogação ou modificação da lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante
- 11.14.11.9. Da reclamação
- 11.14.11.10. Responsabilidade do administrador público
- 11.14.11.11. Responsabilidade dos magistrados?
- 11.14.12. As 53 súmulas vinculantes (a de número 30 com a publicação suspensa)

- 11.14.13. Aspectos conclusivos

- 11.15. Extinção dos Tribunais de Alçada

- 11.15.1. Histórico nas Constituições

- 11.15.2. O surgimento dos Tribunais de Alçada nos Estados

- 11.15.3. A EC n. 45/2004

- 11.16. Questões

12 - FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

- 12.1. Noções introdutórias

- 12.2. Ministério Público

- 12.2.1. Histórico

- 12.2.1.1. Origens remotas

- 12.2.1.2. Constituição de 1824

- 12.2.1.3. Constituição de 1891

- 12.2.1.4. Constituição de 1934

- 12.2.1.5. Constituição de 1937

- 12.2.1.6. Constituição de 1946

- 12.2.1.7. Constituição de 1967

- 12.2.1.8. Emenda Constitucional n. 1/69

- 12.2.1.9. Constituição de 1988

- 12.2.2. Definição e investidura (“quarentena de entrada”)
- 12.2.3. Organização do Ministério Público na CF/88 — art. 128, I e II, e MP Eleitoral
 - 12.2.3.1. Organização do Ministério Público da União e Estadual
 - 12.2.3.2. MP Eleitoral
- 12.2.4. Chefe do Ministério Público
 - 12.2.4.1. Procurador-Geral da República
 - 12.2.4.2. Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios
 - 12.2.4.3. Procurador-Geral do Trabalho
 - 12.2.4.4. Procurador-Geral da Justiça Militar
 - 12.2.4.5. Procurador-Geral Eleitoral
 - 12.2.4.6. Procurador Regional Eleitoral
 - 12.2.4.7. Novas perspectivas em relação à nomeação do PGR
- 12.2.5. Princípios institucionais
 - 12.2.5.1. Regras gerais
 - 12.2.5.2. Legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual para o ajuizamento de reclamação no STF, sem que se exija a ratificação da inicial pelo PGR
- 12.2.6. Princípio do promotor natural
- 12.2.7. Garantias do Ministério Público
 - 12.2.7.1. Garantias institucionais
 - 12.2.7.1.1. Autonomia funcional
 - 12.2.7.1.2. Autonomia administrativa
 - 12.2.7.1.3. Autonomia financeira
 - 12.2.7.2. Garantias dos membros do Ministério Público

- 12.2.7.2.1. Vitaliciedade
- 12.2.7.2.2. Inamovibilidade
- 12.2.7.2.3. Irredutibilidade de subsídios
- 12.2.7.3. Impedimentos imputados aos membros do Ministério Público (vedações)
- 12.2.7.4. Abrangência das garantias e impedimentos
- 12.2.8. Funções institucionais do Ministério Público
- 12.2.9. A teoria dos “poderes implícitos” e o poder de investigação criminal pelo MP
- 12.2.10. Conselho Nacional do Ministério Público
 - 12.2.10.1. Regras gerais e composição
 - 12.2.10.2. Escolha dos membros do Ministério Público da União
 - 12.2.10.3. Escolha dos 3 membros do Ministério Público dos Estados
 - 12.2.10.4. A sabatina no Senado Federal e a falta de critérios para a indicação dos demais membros do Conselho que não os oriundos da carreira do Ministério Público
 - 12.2.10.5. Esquematização gráfica sobre a indicação dos membros do CNMP
 - 12.2.10.6. Corregedor Nacional
 - 12.2.10.7. Atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
 - 12.2.10.8. Pode o CNMP fixar novo teto remuneratório dos membros e servidores do Ministério Público diferente do estabelecido na CF/88?
 - 12.2.10.9. O CNMP tem competência para realizar controle de constitucionalidade no exercício de suas atribuições?
 - 12.2.10.10. Outras regras

12.2.11. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (art. 130)

12.3. Advocacia pública

12.3.1. A distorção corrigida pela EC n. 19/98

12.3.2. O advogado público pode exercer a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo?

12.3.3. Assessoramento, amplitude vinculativa dos pareceres jurídicos e a responsabilização dos advogados públicos

12.3.4. Contempt of Court: a multa do art. 14, parágrafo único, do CPC/73 e os advogados públicos — ADI 2.652. CPC/2015 — avanço na linha da decisão do STF

12.3.5. Pareceres e Súmula da Advocacia-Geral da União

12.3.6. Advocacia-Geral da União

12.3.6.1. Regras gerais

12.3.6.2. Órgãos da Advocacia-Geral da União

12.3.6.3. Advogado-Geral da União

12.3.6.4. O caso particular do “direito de manifestação” do AGU no controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, § 3.º)

12.3.6.5. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

12.3.6.6. Procuradoria-Geral Federal

12.3.6.7. Procuradoria-Geral do Banco Central

12.3.6.8. A prerrogativa da intimação pessoal dos advogados públicos e a regra no CPC/2015

12.3.6.9. A obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n. 10.910/2004, aplica-se ao rito dos Juizados Especiais Federais?

12.3.6.10. Advogados públicos no âmbito da Administração Federal gozam de 30 ou de 60 dias de férias?

12.3.7. Procuradoria-Geral dos Estados e do Distrito Federal

- 12.3.7.1. Estrutura unitária
 - 12.3.7.2. Nomeação e destituição do Procurador-Geral pelo Governador
 - 12.3.7.3. Garantias e impedimentos dos Procuradores do Estado e do DF
- 12.3.8. Procuradoria-Geral dos Municípios
- 12.3.9. Advocacia pública e os honorários de sucumbência no CPC/2015
- 12.4. Advocacia
- 12.5. Estatuto da oab à luz da jurisprudência do stf
 - 12.5.1. ADIs 1.105 e 1.12763
 - 12.5.1.1. A exegese fixada pelo STF
 - 12.5.1.2. Quadro-resumo
 - 12.5.1.3. Sala de Estado-Maior
 - 12.5.2. ADIs 1.194, 2.522, 3.026, 3.168 e 3.541
 - 12.5.3. Constitucionalidade do Exame de Ordem: vitória para os bacharéis em direito e conquista da sociedade
 - 12.5.4. Súmula Vinculante 5/STF x Súmula 343/STJ
 - 12.5.5. Súmula Vinculante 47/2015
- 12.6. Defensoria Pública68
 - 12.6.1. “Ondas renovatórias”
 - 12.6.2. Assistência jurídica integral e gratuita — aspectos gerais e evolução constitucional
 - 12.6.3. Regras gerais
 - 12.6.4. O fortalecimento da Defensoria Pública pela EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário), bem como pelas ECs ns. 69/2012 e 74/2013
 - 12.6.5. Autonomia da Defensoria Pública da União — DPU. Constitucionalidade da EC n. 74/2013. A pretensão formulada na ADI 5.296 (10.04.2015) mostra-se totalmente infundada
 - 12.6.6. As profundas alterações introduzidas pela EC n.

80/2014

12.6.6.1. Visão topológica

12.6.6.2. Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado

12.6.6.3. Princípios institucionais

12.6.6.4. Número de defensores públicos na unidade jurisdicional

12.6.6.5. O defensor público, uma vez nomeado e tendo tomado posse, tem o dever de continuar inscrito nos quadros da OAB?

12.6.7. Existe Defensoria Pública Municipal?

12.6.8. Princípio do defensor público natural

12.6.9. Algumas problemáticas já decididas pela jurisprudência do STF e do STJ

12.6.9.1. A indispensabilidade do concurso público para ingresso na carreira

12.6.9.2. Servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no “exercício regular” de suas funções tem direito à “assistência judiciária” do Estado? Essa atribuição pode ser destinada à Defensoria Pública Estadual?

12.6.9.3. Prazo em dobro e intimação pessoal: prerrogativas da Defensoria Pública. A questão da regra do prazo em dobro para o processo penal. “Lei ainda constitucional”

12.6.9.4. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para Procuradores do Estado no exercício da assistência judiciária, como foi o caso de São Paulo?

12.6.9.5. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para os advogados dativos?

12.6.9.6. As prerrogativas do prazo em dobro e intimação pessoal para a Defensoria Pública aplicam-se ao rito especial dos Juizados?

12.6.9.7. Como ficou a prerrogativa do prazo em dobro e da intimação pessoal no CPC/2015?

12.6.9.8. Defensor público pode exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais?

12.6.9.9. Inconstitucionalidade progressiva — art. 68 do CPP — “lei ainda constitucional”

12.6.9.10. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública?

12.6.9.11. O Defensor Público pode receber honorários advocatícios? Como ficou no CPC/2015?

12.6.9.12. O Defensor Público tem a garantia da vitaliciedade ou a da estabilidade?

12.6.9.13. O Defensor Público tem a garantia da inamovibilidade?

12.6.9.14. Remuneração

12.6.9.15. O Defensor Público tem poder de requisição?

12.6.9.16. A Defensoria Pública Estadual e a Distrital podem atuar nos Tribunais Superiores?

12.6.9.17. É constitucional a imposição por ato normativo da obrigatoriedade de convênio a ser firmado entre a Defensoria Pública e a OAB, para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita?

12.7. Questões⁹⁹

12.7.1. Ministério Público

12.7.2. Advocacia

12.7.3. Defensoria Pública

12.7.4. Geral

13 - DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

13.1. Noções introdutórias — Sistema constitucional das crises¹

13.2. Estado de defesa

- 13.2.1. Hipóteses de decretação do estado de defesa
- 13.2.2. Procedimento e regras gerais
- 13.2.3. Controle exercido sobre a decretação do estado de defesa ou sua prorrogação
- 13.3. Estado de sítio
 - 13.3.1. Hipóteses de decretação do estado de sítio
 - 13.3.2. Procedimento e abrangência
 - 13.3.3. Medidas coercitivas
 - 13.3.4. Controle exercido sobre a decretação do estado de sítio
- 13.4. Disposições comuns aos estados de defesa e de sítio
- 13.5. quadro comparativo entre o estado de defesa e o estado de sítio
- 13.6. Forças Armadas
 - 13.6.1. Regras gerais
 - 13.6.2. Novidades introduzidas pela EC n. 77/2014
 - 13.6.3. Habeas corpus e punições disciplinares militares
 - 13.6.4. Serviço militar obrigatório
 - 13.6.5. Leis de iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, I e II, “f”)
 - 13.6.6. As praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber abaixo do salário mínimo?
 - 13.6.7. Editais de concurso podem estabelecer limite de idade para o ingresso nas Forças Armadas?
 - 13.6.8. “Princípio da insignificância” e crimes militares: o caso concreto de posse de reduzida quantidade de substância entorpecente. Princípio da especialidade. Afastamento da nova Lei de Drogas
 - 13.6.9. Criação do Ministério da Defesa pela EC n. 23/99
- 13.7. Segurança Pública
 - 13.7.1. Aspectos gerais
 - 13.7.2. Cooperação entre a União e os Estados-Membros e o

DF e a Força Nacional de Segurança Pública

13.7.3. BEPE — Batalhão Especial de Pronto Emprego

13.7.4. UPPs — Unidades de Polícia Pacificadora (RJ)

13.7.5. Polícias da União

13.7.5.1 Polícia Federal (PF)

13.7.5.2. Polícia Rodoviária Federal (PRF)

13.7.5.3. Polícia Ferroviária Federal (PFF)

13.7.6. Polícias dos Estados

13.7.6.1. Polícia civil estadual

13.7.6.2. Nos Municípios em que o Departamento de Polícia Civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia de carreira, o atendimento nas delegacias de polícia poderá ser realizado por subtenente ou sargento da polícia militar?

13.7.6.3. Polícia judiciária dos Estados — discussão sobre a escolha do diretor-geral da Polícia Civil. Superação do entendimento firmado na ADI 132. Reconstrução jurisdicional da própria teoria do federalismo (ADI 3.062). Análise da ADI 3.038

13.7.6.4. Polícia ostensiva ou preventiva dos Estados — PM e Corpo de Bombeiros Militares

13.7.7. Polícias do Distrito Federal

13.7.8. Polícias dos Territórios

13.7.9. Policiais civis e militares: direito de greve (?) e anistia (?)

13.7.9.1. Direito de greve?

13.7.9.2. Lei poderá conceder anistia a policiais civis ou militares (PM e Corpo de Bombeiros) em relação a eventuais crimes praticados e infrações disciplinares conexas decorrentes de participação em movimentos reivindicatórios?

13.7.10. Polícias dos Municípios

13.7.11. Segurança viária. Carreira dos agentes de trânsito. EC n. 82/2014

13.7.11.1. Tramitação da EC n. 82/2014

13.7.11.2. A segurança viária é questão de saúde pública

13.7.11.3. Tripé da segurança viária

13.7.11.4. Segurança viária: questão a ser tratada de forma indissociável da segurança pública

13.7.11.5. A carreira específica de agentes de trânsito

13.8. Questões

14 - DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

14.1. Localização

14.2. Evolução dos direitos fundamentais (“gerações” ou “dimensões” de direitos)

14.2.1. Direitos fundamentais da 1.^a dimensão

14.2.2. Direitos fundamentais da 2.^a dimensão

14.2.3. Direitos fundamentais da 3.^a dimensão

14.2.4. Direitos fundamentais da 4.^a dimensão

14.2.5. Direitos fundamentais da 5.^a dimensão

14.3. Diferenciação entre direitos e garantias fundamentais

14.4. Características dos direitos e garantias fundamentais

14.5. Abrangência dos direitos e garantias fundamentais

14.6. A APLICABILIDADE DAS NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

14.7. A teoria dos quatro status de jellinek

14.8. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais

14.8.1. Aspectos gerais

14.8.2. Teorias da eficácia indireta (mediata) ou direta (imediata)

14.8.3. Eficácia “irradiante” dos direitos fundamentais

14.8.4. Alguns precedentes

14.8.5. Brevíssima conclusão

14.9. dEVERES FUNDAMENTAIS

14.10. Direitos individuais e coletivos

14.10.1. Direito à vida (art. 5.º, caput)

14.10.1.1. Aspectos gerais

14.10.1.2. Células-tronco embrionárias

14.10.1.3. Interrupção de gravidez de feto anencefálico

14.10.1.4. Eutanásia

14.10.2. Princípio da igualdade (art. 5.º, caput, I)

14.10.2.1. Aspectos gerais

14.10.2.2. “Separate but equal” e “Treatment as an equal”

14.10.2.3. Ações afirmativas — três importantes precedentes da Suprema Corte (Cotas Raciais, PROUNI e Lei Maria da Penha) e a Lei n. 12.990/2015

14.10.2.4. Ações afirmativas — indicação de Ministros para o STF

14.10.2.5. Princípio da congeneridade

14.10.2.6. Foro da residência da mulher no CPC/73. Nova regra trazida pelo CPC/2015 (foro de domicílio do guardião de filho incapaz)

14.10.2.7. Art. 384 da CLT: intervalo de 15 minutos para as mulheres antes de hora extra

14.10.3. Princípio da legalidade (art. 5.º, II)

14.10.4. Proibição da tortura (art. 5.º, III)

14.10.5. Liberdade da manifestação de pensamento (art. 5.º, IV e V)

14.10.5.1. Liberdade de expressão e a problemática

do “hate speech”. “Posição de preferência” da liberdade de expressão. Interessante exemplo no âmbito da rede mundial de computadores (“marco civil da internet” — Lei n. 12.965/2014)

14.10.5.2. Ainda a problemática do “hate speech” (discursos de incitação ao ódio). Liberdade de expressão e a prática do crime de racismo: precedente histórico na jurisprudência do STF — HC 82.424. A liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto

14.10.5.3. Delação anônima

14.10.5.4. “Marcha da maconha”

14.10.6. Liberdade de consciência, crença e culto (art. 5.º, VI a VIII)

14.10.6.1. Regras gerais

14.10.6.2. Ensino religioso nas escolas

14.10.6.3. Feriados religiosos

14.10.6.4. Casamento perante autoridades religiosas

14.10.6.5. Transfusão de sangue nas Testemunhas de Jeová

14.10.6.6. Curandeirismo

14.10.6.7. Crucifixos em repartições públicas

14.10.6.8. Imunidade religiosa

14.10.6.9. Guarda sabática

14.10.6.10. A expressão “Deus seja louvado” nas cédulas de real

14.10.6.11. Aspectos conclusivos

14.10.7. Liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Indenização em caso de dano (art. 5.º, IX e X)

14.10.8. Intimidade e vida privada e o sigilo bancário (art. 5.º, X)

- 14.10.9. Inviolabilidade domiciliar (art. 5.º, XI)
- 14.10.10. Sigilo de correspondência e comunicações (art. 5.º, XII)
- 14.10.11. Liberdade de profissão (art. 5.º, XIII)
- 14.10.12. Liberdade de informação (art. 5.º, XIV e XXXIII)
- 14.10.13. Liberdade de locomoção (art. 5.º, XV e LXI)
- 14.10.14. Direito de reunião (art. 5.º, XVI)
- 14.10.15. Direito de associação (art. 5.º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI)
- 14.10.16. Direito de propriedade (art. 5.º, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI)
- 14.10.17. Direito de herança e estatuto sucessório (art. 5.º, XXX e XXXI)
- 14.10.18. Propriedade intelectual (art. 5.º, XXVII, XXVIII e XXIX)
- 14.10.19. Defesa do consumidor (art. 5.º, XXXII)
- 14.10.20. Direito de petição e obtenção de certidões (art. 5.º, XXXIV)
- 14.10.21. Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV)
- 14.10.22. Limites à retroatividade da lei (art. 5.º, XXXVI)
- 14.10.23. Princípio do promotor natural (art. 5.º, LIII)
- 14.10.24. Princípio do juiz natural ou legal (art. 5.º, XXXVII e LIII)
- 14.10.25. Tribunal Penal Internacional — “TPI” (art. 5.º, § 4.º — EC n. 45/2004)
- 14.10.26. Federalização dos crimes contra direitos humanos (art. 109, V-A e § 5.º — EC n. 45/2004) — Incidente de deslocamento de competência — IDC
- 14.10.27. Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII)
- 14.10.28. Segurança jurídica em matéria criminal (art. 5.º, XXXIX a LXVII) e a teoria dos mandados expressos de

criminalização à luz dos direitos fundamentais

14.10.28.1. Legalidade e anterioridade da lei penal incriminadora. Irretroatividade da lei penal “in pejus” (art. 5.º, XXXIX e XL)

14.10.28.2. Práticas discriminatórias, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e crimes inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5.º, XLI a XLIV)

14.10.28.3. Regras constitucionais sobre as penas (art. 5.º, XLV a XLVIII)

14.10.28.4. Direitos assegurados aos presos (art. 5.º, XLIX, L, LXII, LXIII e LXIV)

14.10.28.5. Regras sobre extradição (art. 5.º, LI e LII)

14.10.28.6. Presunção de inocência (não culpabilidade) (art. 5.º, LVII)

14.10.28.7. Regras sobre a prisão (art. 5.º, LXI, LXV, LXVI, LXVII)

14.10.28.8. Identificação criminal (art. 5.º, LVIII)

14.10.28.9. Ação penal privada subsidiária da pública (art. 5.º, LIX)

14.10.29. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV)

14.10.29.1. Aspectos gerais

14.10.29.2. Interrogatório por videoconferência (online)

14.10.29.3. Transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima

14.10.29.4. Art. 98 do antigo Regimento Interno do CNJ: necessidade de intimação pessoal de terceiros que demonstrem interesse jurídico nos procedimentos de controle administrativo (PCAs). Correção no novo RI

14.10.30. Devido processo legal substantivo ou material (arts. 5.o, LV, e 3.o, I)

14.10.31. Provas ilícitas (art. 5.º, LVI)

14.10.32. Publicidade dos atos processuais (e dever de motivação das decisões judiciais) (art. 5.º, LX). Perspectivas do CPC/2015

14.10.33. Assistência jurídica integral e gratuita (art. 5.º, LXXIV)

14.10.34. Erro judiciário (art. 5.º, LXXV)

14.10.35. Gratuidade das certidões de nascimento e de óbito (art. 5.º, LXXVI)

14.10.36. Gratuidade nas ações de habeas corpus e habeas data (art. 5.º, LXXVII)

14.10.37. Celeridade processual (art. 5.º, LXXVIII)

14.10.37.1. Aspectos gerais

14.10.37.2. Celeridade do processo e crimes praticados contra os idosos

14.10.37.3. Leis infraconstitucionais decorrentes da EC n. 45/2004 (“Reforma do Poder Judiciário”)130 no sentido de “racionalização da prestação jurisdicional” — frutos dos “Pactos Republicanos”

14.11. Remédios constitucionais

14.11.1. Os remédios constitucionais nas Constituições brasileiras — quadro esquematizado

14.11.2. Habeas corpus (art. 5.º, LXVIII)132

14.11.2.1. Regras gerais

14.11.2.2. Esquematização da evolução histórica do “HC” no constitucionalismo brasileiro

14.11.2.3. Competência

14.11.2.4. Espécies

14.11.2.5. Punições disciplinares militares

14.11.2.6. “Habeas corpus” impetrado em face de ato

da “Turma Recursal” — competência do TJ —
superada a S. 690/STF

14.11.3. Mandado de segurança (art. 5.º, LXIX)

14.11.3.1. Introdução

14.11.3.2. Esquematização da evolução histórica do
“MS” no constitucionalismo brasileiro¹³⁸

14.11.3.3. Abrangência

14.11.3.4. Direito líquido e certo

14.11.3.5. Ilegalidade ou abuso de poder

14.11.3.6. Legitimidade ativa e passiva

14.11.3.7. Competência

14.11.3.8. Algumas outras observações

14.11.4. Mandado de segurança coletivo (art. 5.º, LXX)

14.11.4.1. Regras gerais

14.11.4.2. Objeto, legitimidade ativa e objetivos

14.11.4.2.1. Objeto

14.11.4.2.2. Legitimidade ativa

14.11.4.2.2.1. Partidos políticos

14.11.4.2.2.2. Organizações sindicais,
entidades de classe e associações

14.11.4.2.3. Objetivos

14.11.5. Mandado de injunção (art. 5.º, LXXI)

14.11.5.1. Aspectos gerais

14.11.5.2. Legitimidade ativa e passiva

14.11.5.3. Competência

14.11.5.4. Procedimento e efeitos da decisão

14.11.5.5. Perspectivas de um “ativismo judicial”

14.11.6. Habeas data (art. 5.º, LXXII)

14.11.6.1. Aspectos gerais

14.11.6.2. Legitimidade ativa e passiva

14.11.6.3. Procedimento

14.11.6.4. Competência

14.11.7. Ação popular (art. 5.º, LXXIII)

14.11.7.1. Aspectos gerais

14.11.7.2. Esquematização da evolução histórica da “ação popular” no constitucionalismo brasileiro

14.11.7.3. Requisitos

14.11.7.4. Legitimidade ativa e passiva

14.11.7.5. Competência

14.11.7.5.1. Regra geral — juízo de primeiro grau

14.11.7.5.2. SEBRAE — competência da Justiça comum

14.11.7.5.3. Ação popular contra o CNMP — incompetência do STF

14.11.7.5.4. Incompetência originária do STF e indicação do órgão competente

14.11.7.6. Outras regras

14.12. Questões

14.12.1. Direitos fundamentais

14.12.2. Remédios constitucionais

15 - DIREITOS SOCIAIS

15.1. ASPECTOS GERAIS

15.2. BREVES COMENTÁRIOS AOS DIREITOS SOCIAIS

15.2.1. Direito à educação

15.2.2. Direito à saúde

15.2.3. Direito à alimentação

15.2.4. Direito ao trabalho

15.2.5. Direito à moradia

15.2.6. Direito ao lazer

15.2.7. Direito à segurança

15.2.8. Direito à previdência social

15.2.9. Proteção à maternidade e à infância

15.2.10. Assistência aos desamparados

15.3. “PEC DA FELICIDADE” — pec n. 513/2010-CD e PEC n. 19/2010-SF

15.4. DIREITOS RELATIVOS AOS TRABALHADORES⁴

15.4.1. Direitos sociais individuais dos trabalhadores

15.4.2. Direitos sociais coletivos dos trabalhadores (arts. 8.º a 11)

15.4.2.1. Direito de associação profissional ou sindical

15.4.2.2. Direito de greve

15.4.2.3. Direito de substituição processual

15.4.2.4. Direito de participação

15.4.2.5. Direito de representação classista

15.5. “METODOLOGIA FUZZY” E “CAMALEÕES NORMATIVOS” NA PROBLEMÁTICA DOS DIREITOS SOCIAIS, CULTURAIS E ECONÔMICOS (CANOTILHO)⁸

15.5.1. Princípio do não retrocesso social ou da proibição da evolução reacionária. Interpretação a ser dada à EC n. 86/2015 (fruto da “PEC do Orçamento Impositivo”)

15.5.2. Mínimo existencial: concretização dos direitos sociais e a implementação de políticas públicas

15.6. QUESTÕES

16 - NACIONALIDADE

16.1. Conceito

16.1.1. Definições correlatas

16.2. Espécies de nacionalidade e critérios para a sua aquisição

16.3. Brasileiro nato

16.4. Brasileiro naturalizado

16.4.1. Noções introdutórias: procedimento

16.4.2. Naturalização ordinária

16.4.3. Naturalização extraordinária ou quinquenária

16.4.4. Radicação precoce e conclusão de curso superior?

16.5. QUASE NACIONALIDADE — PORTUGUESES — ART. 12, § 1.º — reciprocidade

16.6. A lei poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados?

16.6.1. Regra geral

16.6.2. Hipóteses taxativas de exceção à regra geral

16.6.2.1. Extradicação

16.6.2.1.1. Extradicação ativa

16.6.2.1.2. Extradicação passiva: brasileiro nato x brasileiro naturalizado

16.6.2.1.3. Extradicação passiva: regras procedimentais

16.6.2.1.4. Extradicação passiva: vedações legais

16.6.2.1.5. Extradicação passiva: e se o extraditando for casado com brasileira ou tiver filho brasileiro? Haverá óbice, por esse motivo, ao pedido de extradicação?

16.6.2.1.6. Extradicação passiva: entendendo o STF pela procedência do pedido de extradicação, o Presidente da República será obrigado a extraditar o requisitado?

16.6.2.1.7. Expulsão

16.6.2.1.8. Deportação

16.6.2.1.9. Banimento: existe expulsão ou banimento de brasileiros?

16.6.2.1.10. Asilo político e refúgio (direito de permanecer no Brasil)

16.6.2.2. Cargos privativos de brasileiros natos

16.6.2.3. Atividade nociva ao interesse nacional

16.6.2.4. Conselho da República

16.6.2.5. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

16.7. Perda da nacionalidade

16.7.1. Hipóteses de perda da nacionalidade

16.7.1.1. Cancelamento da naturalização

16.7.1.2. Aquisição de outra nacionalidade

16.8. Reaquisição da nacionalidade brasileira perdida

16.9. Questões

17 - DIREITOS POLÍTICOS

17.1. Noções introdutórias

17.1.1. Democracia semidireta ou participativa

17.1.2. Plebiscito versus referendo: experiências na história brasileira

17.1.2.1. Referendo para manutenção ou não do regime parlamentarista (1963)

17.1.2.2. Plebiscito para a escolha entre a forma (república ou monarquia constitucional) e sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) (1993)

17.1.2.3. Referendo para a manifestação do eleitorado sobre a manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional (2005)

17.1.2.4. Referendo no Estado do Acre para decidir

sobre o fuso horário (2010)

17.1.2.5. Plebiscitos no Estado do Pará para decidir sobre a formação dos Estados do Carajás e do Tapajós (2011)

17.1.3. O resultado do plebiscito ou do referendo pode ser modificado por lei ou emenda à Constituição?

17.1.4. Quadro comparativo: plebiscito versus referendo

17.1.5. Outros institutos de democracia semidireta ou participativa: recall e veto popular

17.2. Soberania popular, nacionalidade, cidadania, sufrágio, voto e escrutínio

17.3. Direito político positivo (direito de sufrágio)

17.3.1. Capacidade eleitoral ativa

17.3.2. Capacidade eleitoral passiva

17.3.2.1. Condições de elegibilidade

17.4. Direitos políticos negativos

17.4.1. Inelegibilidades

17.4.1.1. Inelegibilidades absolutas

17.4.1.2. Inelegibilidades relativas

17.4.1.2.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida (por motivos funcionais)

17.4.1.2.1.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida para um terceiro mandato sucessivo

17.4.1.2.1.2. A figura do denominado “prefeito itinerante” ou “prefeito profissional”

17.4.1.2.1.3. Inelegibilidade relativa em razão da função para concorrer a outros cargos

17.4.1.2.2. Inelegibilidade relativa em razão do parentesco

17.4.1.2.3. Militares

17.4.1.2.4. Inelegibilidades previstas em lei complementar

17.4.2. Candidatos com “ficha suja”: inelegibilidade?

17.4.3. Privação dos direitos políticos — perda e suspensão

17.4.3.1. Perda dos direitos políticos (arts. 15, I e IV, e 12, § 4.º, II, da CF/88)

17.4.3.2. Suspensão dos direitos políticos (arts. 15, II, III e V, e 55, II, e § 1.º, da CF/88; art. 17.3 do Dec. n. 3.927/2001 c/c o art. 1.º, I, “b”, da LC n. 64/90)

17.4.4. Reaquisição dos direitos políticos perdidos ou suspensos

17.5. Servidor público e exercício do mandato eletivo

17.6. Questões

18 - PARTIDOS POLÍTICOS E O FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS

18.1. Conceito

18.2. Regras constitucionais

18.3. Inconstitucionalidade da cláusula de barreira — proteção constitucional às minorias

18.4. O princípio da verticalização das coligações partidárias e a EC n. 52/2006

18.4.1. Primeiro momento — a consagração da regra da verticalização das coligações partidárias pelo TSE

18.4.2. Ataques à regra da verticalização das coligações partidárias fixada pelo TSE

18.4.3. Ataques à regra da EC n. 52/2006, que expressamente acabou com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Mantida a verticalização para as eleições de 2006 (princípio da anualidade — art. 16 da CF). A EC n. 52/2006 entrou em vigor na data de sua publicação, mas somente poderá ser aplicada às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência

18.5. fidelidade partidária

18.6. a vaga decorrente do licenciamento de titulares de mandato parlamentar deve ser ocupada pelos suplentes das coligações OU dos partidos?

18.7. FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS — ADI 4.650

18.8. QUESTÕES

19 - ORDEM SOCIAL

19.1. ASPECTOS GERAIS

19.1.1. Valores da ordem social: base e objetivo

19.1.2. Conteúdo da ordem social

19.2. SEGURIDADE SOCIAL

19.2.1. Princípios orientadores da organização da seguridade social

19.2.2. Financiamento da seguridade social

19.2.3. Competência discriminada (lei ordinária) e competência residual (lei complementar)

19.2.4. Inconstitucionalidade do art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718/98 (PIS/PASEP e COFINS). EC n. 20/98 — impossibilidade do fenômeno da “constitucionalidade superveniente”

19.2.5. Cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para sociedades civis de profissões regulamentadas

19.2.5.1. Inexistência de hierarquia entre LC e LO

19.2.5.2. A questão da modulação dos efeitos da decisão pelo STF

19.3. EDUCAÇÃO — FUNDEB — EC N. 53/2006

19.3.1. Aspectos gerais

19.3.2. Quadro esquematizado da educação escolar

19.3.3. Regras gerais do fundo

19.3.4. Fim (progressivo) da DRU para a educação e as ECs ns. 59/2009 e 68/2011

19.4. CULTURA

19.4.1. Plano Nacional de Cultura (EC n. 48/2005)

19.4.2. Sistema Nacional de Cultura (EC n. 71/2012)

19.5. DESPORTO

19.5.1. Desporto em sentido amplo

19.5.2. Modalidades de desporto

19.5.3. Papel do Estado e das entidades dirigentes e associações na promoção do desporto

19.5.4. Destinação dos recursos públicos para o desporto

19.5.5. Manifestações desportivas de “criação nacional”

19.5.6. Justiça Desportiva

19.5.6.1. Regras gerais, natureza jurídica e composição

19.5.6.2. Instância administrativa de curso forçado: exceção ao princípio do acesso incondicionado ao Poder Judiciário. Necessidade de esgotamento das vias administrativas

19.5.6.3. Questões trabalhistas: competência da Justiça do Trabalho

19.5.6.4. Vedação do exercício de funções na Justiça Desportiva por integrantes do Poder Judiciário

19.5.7. Bingos

19.6. CIÊNCIA, TECNOLOGIA e inovação (EC n. 85/2015)

19.6.1. Perspectivas introduzidas pela EC n. 85/2015

19.6.2. O papel do Estado

19.6.3. Modalidades de pesquisa e o tratamento prioritário do Estado

19.6.4. Apoio e incentivo do Estado

19.6.5. Estado Social de Direito: concepção social do mercado

19.6.6. O destaque para a biotecnologia

19.7. COMUNICAÇÃO SOCIAL

19.7.1. Princípios orientadores da comunicação social

19.7.2. Princípios a orientar a produção e a programação das emissoras de rádio e TV

19.7.3. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

19.7.4. Serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (TV)

19.7.4.1. Diferenciação entre os serviços de telecomunicação e de radiodifusão (EC n. 8/95)

19.7.4.2. Concessão, permissão e autorização

19.7.4.3. Prazo da concessão ou permissão e da autorização

19.7.4.4. Outorga e renovação (da concessão ou permissão e da autorização)

19.7.4.5. Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T): consignação de mais um canal de radiofrequência às concessionárias e “autorizadas” dos serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens, sem apreciação do Congresso Nacional

19.7.5. Conselho de Comunicação Social: órgão auxiliar do CN

19.7.6. Direito de antena

19.7.7. Lei de Imprensa — ADPF 130

19.7.8. “Lei Eleitoral sobre o Humor”

19.8. MEIO AMBIENTE

19.8.1. Conceito de meio ambiente

19.8.2. Aspectos do meio ambiente

19.8.3. Direitos humanos, direito ao desenvolvimento e direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações

- 19.8.3.1. A problemática
- 19.8.3.2. Sustentabilidade: solução para a problemática
- 19.8.4. A proteção ambiental no constitucionalismo brasileiro
- 19.8.5. Natureza jurídica do meio ambiente e a justiça distributiva entre as presentes e futuras gerações
- 19.8.6. Incumbência do Poder Público
- 19.8.7. Crueldade contra animais?
 - 19.8.7.1. Farra do boi
 - 19.8.7.2. Rinhas ou brigas de galo
 - 19.8.7.3. Rodeios de animais, vaquejada, “calf roping” e “team roping” (laçada dupla)
 - 19.8.7.4. Animais em circo
 - 19.8.7.4.1. A origem do circo — breve nota⁴⁴
 - 19.8.7.4.2. O adestramento de animais em circos
 - 19.8.7.4.3. O fim dos animais em circos significaria o fim da cultura circense?
- 19.8.8. Importação de pneus usados — ADPF 101
- 19.8.9. Exploração de recursos minerais
- 19.8.10. Responsabilidade por danos ambientais
- 19.8.11. Ecossistemas especialmente protegidos e erigidos à categoria de patrimônio nacional
- 19.8.12. Os “Soldados da Borracha” e a EC n. 78/2014
- 19.8.13. Terras devolutas
 - 19.8.13.1. Classificação dos bens públicos: as terras devolutas enquanto bens dominicais
 - 19.8.13.2. Titularidade
 - 19.8.13.3. Terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado necessárias à proteção dos ecossistemas

naturais — indisponibilidade

19.8.14. Localização das usinas nucleares: necessidade de lei federal

19.9. FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE, jovem E IDOSO

19.9.1. Família: conceito de entidade familiar

19.9.2. União homoafetiva (união estável entre pessoas do mesmo sexo)

19.9.3. Transexualidade

19.9.4. A união estável pode ser reconhecida em relação a uma menor de 14 anos estuprada que veio a se casar com o agressor, para efeitos de extinção de punibilidade quando era admitida (antes da revogação do art. 107, VII, do CP)?

19.9.5. Família: assistência e proteção contra a violência doméstica. As particularidades da denominada Lei Maria da Penha (ADC 19 e ADI 4.424)

19.9.5.1. Lei Maria da Penha: instrumento de proteção efetiva dos direitos fundamentais

19.9.5.2. Não aplicação da Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)

19.9.5.3. Constitucionalidade das regras até que sejam estruturados os “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”

19.9.5.4. Crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher: ação penal pública incondicionada

19.9.6. Casamento: regras gerais; gratuidade da celebração; efeito civil; liberdade de crença (centro espírita, candomblé, umbanda etc.)

19.9.7. Divórcio: forma de dissolução do casamento civil à luz da EC n. 66/2010

19.9.8. Liberdade para o planejamento familiar: dignidade da pessoa humana e paternidade responsável

19.9.9. Criança, adolescente e jovem (EC n. 65/2010)

- 19.9.10. Criança, adolescente e jovem: proteção especial
- 19.9.11. Alienação parental
- 19.9.12. Adoção
 - 19.9.12.1. Regras gerais sobre adoção
 - 19.9.12.2. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6.º. Posição do STF na AR 1.811
 - 19.9.12.3. Adoção internacional
 - 19.9.12.4. Adoção por casal homoafetivo ou transexual
- 19.9.13. Direito de ação de investigação de paternidade: a problemática da submissão coercitiva ao exame de DNA
- 19.9.14. Portadores de deficiência
- 19.9.15. Inimputabilidade penal
- 19.9.16. Dever de reciprocidade entre pais e filhos
- 19.9.17. Idosos
 - 19.9.17.1. Princípios da solidariedade e proteção à luz da “reserva do possível”
 - 19.9.17.2. Idoso e transporte público: “constitucionalismo fraternal” ou “altruístico” — “ações distributivistas e solidárias” — “direito fraternal”
 - 19.9.17.3. Celeridade do processo e crimes praticados contra os idosos

19.10. ÍNDIOS

- 19.10.1. Os índios no constitucionalismo brasileiro
- 19.10.2. Proteção das “minorias nacionais” e a importância da “terra”
- 19.10.3. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
 - 19.10.3.1. Bens da União. Terras destinadas à posse permanente dos índios: bens públicos de uso especial

19.10.3.2. Conceito

19.10.3.3. Nulidade e extinção dos atos que atentem contra as “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”

19.10.4. Indigenato: fonte para o direito dos índios sobre as suas terras

19.10.5. Usufruto exclusivo dos índios e a mineração em terras indígenas

19.10.6. Regras constitucionais para a remoção dos grupos indígenas

19.10.7. Demarcação das terras indígenas

19.10.7.1. Aspectos gerais

19.10.7.2. Raposa Serra do Sol

19.10.8. Defesa judicial dos direitos e interesses dos índios

19.10.8.1. Legitimidade ativa: índios, comunidades, organizações e o MP (Federal ou Estadual)

19.10.8.2. Competência: Justiça Federal x Justiça Estadual

19.10.9. Educação nas comunidades indígenas

19.10.10. Infanticídio indígena

19.11. QUESTÕES

20 - ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

20.1. PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

20.1.1. Evolução do Estado e a Ordem Econômica

20.1.2. Separação da Ordem Econômica e da Ordem Social

20.1.3. Meios de atuação do Estado

20.1.4. Princípios da Ordem Econômica

20.1.4.1. Soberania nacional

20.1.4.2. Propriedade privada e sua função social

20.1.4.3. Livre concorrência

- 20.1.4.4. Defesa do consumidor
- 20.1.4.5. Defesa do meio ambiente
- 20.1.4.6. Redução das desigualdades regionais e sociais
- 20.1.4.7. Busca do pleno emprego
- 20.1.4.8. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte

20.2. MONOPÓLIO DOS CORREIOS

20.3. QUEBRA DO MONOPÓLIO DA UNIÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS PARA A PESQUISA E USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, BEM COMO SOBRE A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA (EC N. 49/2006)

20.4. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

20.5. QUESTÕES

21 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

21.1. justificativas iniciais

21.2. REPÚBLICA

21.3. federação

21.4. estado democrático de direito

21.4.1. Aspectos gerais

21.4.2. A Lei da Anistia, a ADPF 153 e a decisão da “Corte Interamericana de Direitos Humanos”

21.5. SEPARAÇÃO DE “PODERES”

21.6. Fundamentos da República Federativa do Brasil

21.7. objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil

21.8. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais

21.8.1. Art. 4.º, CF/88

21.8.2. MERCOSUL

21.8.3. MERCOSUL — evolução do Sistema de Solução de Controvérsias. Tribunal Permanente de Revisão (TPR)

21.9. Questões

22 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OUTROS TEMAS

22.1. EXPLICITAÇÃO DA PROPOSTA

22.2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

22.2.1. Princípio da legalidade

22.2.2. Princípio da impessoalidade

22.2.2.1. A questão específica das vagas previstas em edital e o direito subjetivo à nomeação: princípio da confiança

22.2.2.2. IBGE: contratação temporária, sem concurso, para demandas sazonais de pesquisa

22.2.2.3. Contratação pela administração pública, de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público (EC n. 51/2006)

22.2.3. Princípio da moralidade administrativa

22.2.4. Princípio da publicidade

22.2.5. Princípio da eficiência

22.2.6. Nepotismo

22.3. “PEC PARALELA DA PREVIDÊNCIA” (EC N. 47/2005)

22.3.1. Notas introdutórias

22.3.2. Teto do funcionalismo (art. 37, §§ 11 e 12)

22.3.2.1. Regras gerais

22.3.2.2. Importantes questões já decididas pelo STF

22.3.3. Aposentadorias especiais (arts. 40, § 4.º, I, II e III, e 201, § 1.º)

22.3.4. Aumento da faixa de isenção de contribuição previdenciária para os servidores inativos e os pensionistas que sejam, nos termos da lei, portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21)

22.3.5. Ampliação das hipóteses de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas das contribuições sociais para o financiamento da seguridade social (art. 195, § 9.º)

22.3.6. Ampliação do sistema especial de inclusão previdenciária (art. 201, §§ 12 e 13)

22.3.7. Paridade plena entre ativos e inativos (arts. 2.º e 5.º da EC n. 47/2005)

22.3.8. Regra geral de transição (art. 3.º da EC n. 47/2005)

22.3.9. Vigência da EC n. 47/2005 (art. 6.º)

22.4. EC N. 55/2007

22.5. “PEC DOS AGENTES DE SAÚDE” — EC N. 63/2010

22.6. EC N. 70/2012

22.7. EC N. 75/2013

22.8. EC N. 84/2014

REFERÊNCIAS

Histórico da Obra

- **1.^a edição:** jan./2000
- **2.^a edição:** jun./2001
- **3.^a edição:** fev./2002
- **4.^a edição:** ago./2002
- **5.^a edição:** fev./2003
- **6.^a edição:** maio/2003; 2.^a tir., set./2003
- **7.^a edição:** jan./2004; 2.^a tir., fev./2004; 3.^a tir., mar./2004; 4.^a tir., abr./2004; 5.^a tir., maio/2004;
- **6.^a edição:** tir., jul./2004; 7.^a tir., ago./2004; 8.^a tir., set./2004; 9.^a tir., out./2004
- **8.^a edição:** fev./2005; 2.^a tir., mar./2005; 3.^a tir., maio/2005; 4.^a tir., jun./2005
- **9.^a edição:** out./2005; 2.^a tir., jan./2006
- **10.^a edição:** mar./2006; 2.^a tir., maio/2006; 3.^a tir., jul./2006; 4.^a tir., set./2006; 5.^a tir., nov./2006
- **11.^a edição:** mar./2007; 2.^a tir., abr./2007; 3.^a tir., maio/2007; 4.^a tir., ago./2007; 5.^a tir., set./2007; 6.^a tir., out./2007
- **12.^a edição:** mar./2008; 2.^a tir., mar./2008; 3.^a tir., abr./2008; 4.^a tir., jun./2008; 5.^a tir., ago./2008; 6.^a tir., ago./2008; 7.^a tir., out./2008
- **13.^a edição:** fev./2009; 2.^a tir., mar./2009; 3.^a tir., abr./2009; 4.^a tir., jul./2009; 5.^a tir., ago./2009; 6.^a tir., set./2009
- **14.^a edição:** fev./2010; 2.^a tir., mar./2010; 3.^a tir., jul./2010; 4.^a tir., ago./2010; 5.^a tir., set./2010
- **15.^a edição:** fev./2011; 2.^a tir., maio/2011; 3.^a tir., ago./2011
- **16.^a edição:** fev./2012; 2.^a tir., jul./2012; 3.^a tir., set./2012
- **17.^a edição:** mar./2013; 2.^a tir., ago./2013; 3.^a tir., out./2013
- **18.^a edição:** fev./2014; 2.^a tir., set./2014; 3.^a tir., out./2014; 4.^a tir., fev./2015; 5.^a tir., mar./2015; 6.^a tir., abr./2015; 7.^a tir., maio/2015
- **19.^a edição:** jul./2015

Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP

Advogado e Professor



UMA HOMENAGEM ESPECIAL

Gostaria de pedir licença ao meu ilustre leitor e fazer um agradecimento que, apesar de particular, é muito especial...

Gostaria de agradecer a você, minha querida Má, por tudo o que representa, não só em minha vida como também para o resultado deste nosso “filho”.

Como muitos devem saber, o “nosso” *Esquematizado*[®] surgiu no ano de 2000, como um sonho e a concretização de um projeto de vida...

Hoje, depois de 14 anos, com milhares de exemplares vendidos, gostaria de confessar que tudo isso — além das muitas pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram, inclusive o meu ilustre leitor, fiel e amigo, que constantemente envia sugestões — tem a mão de uma pessoa chamada Má.

Todos devem presumir a dificuldade que é “lutar”, diária, diuturna e, também, literalmente, durante muitas e muitas noites de estudo, para que o livro continue a cumprir o seu relevante papel na vida de muitas pessoas...

Todos podem imaginar os momentos de dificuldade, de esgotamento... que poderiam se comparar à luta diária dos concurseiros de nosso país, que se “fecham” ao mundo, que se afastam dos entes queridos, que se privam de momentos prazerosos, sempre em busca de um sonho muito nobre, de um projeto de vida, marcado por horas e mais horas isolados: o concurseiro “guerreiro”, os livros, o quarto, a biblioteca e Deus para nos guiar.

Muitas vezes nos perguntamos, eu inclusive, se tudo está valendo a pena, se tanto esforço está valendo a pena, se, pela fragilidade da vida, devemos continuar nessa trajetória.

Então, é nesses momentos de dificuldade que vejo a importância que é ter uma pessoa como a Má: atrás, para me segurar nos momentos difíceis, projetando-me para o sonho; à frente, servindo como força propulsora; e ao lado, me estimulando, encorajando, incentivando e entusiasmando...

Posso dizer, então, que tudo isso que o *Esquematizado*® hoje representa tem a mão da Má, que nunca deixou de sonhar este nosso sonho.

Muitas horas, muitas noites... Assim, depois de tanta coisa que passamos juntos, eu só tenho a lhe agradecer por tudo, Má, especialmente por sua alegria de vida, a contribuir para a realização do sonho de muitos e ilustres “concurseiros” que, honrosamente, acreditaram em “nosso” *Esquematizado*®.

Assim, Má, por tudo e para sempre, o meu muito obrigado por ajudar a manter vivo este nosso sonho.

Precisava dividir essa felicidade e berrar para todo mundo que eu te amo muuuuuito e, de alguma maneira, te dizer o quanto você é importante nisso tudo e na minha vida! Valeu...



MAIS UMA HOMENAGEM ESPECIAL [1](#)

Gostaria de pedir novamente licença ao meu ilustre leitor e fazer mais um agradecimento que, apesar de particular, é, também, muito especial...

Com a graça de Deus (porque ter um filho é uma bênção), eu e a Má esperávamos nossa filha para o dia 20 de julho de 2010. Apressadinha como os pais, no dia 25 de maio de 2010, a pequena (literalmente, porque prematura) Manoela veio ao mundo.

Realmente, como muitos diziam, a minha vida mudou! Tudo é muito estranho e novo. Como é possível que aquele “tesouro” tenha saído da barriga da minha esposa?

Dizem que se parece um pouco comigo, e fico, mais ainda, impressionado. Como é a natureza!

E agora, pela primeira vez, estou vivenciando a emoção de ser pai... Que explosão de sentimentos! Realmente, o mundo fica paralisado quando eu fico olhando nos olhos dela...

Acho que tudo passa a fazer sentido. Tanta luta diária, tantas noites sem dormir (escrevendo, atualizando os livros, em solitário enclausuramento), tantos sonhos sonhados... Agora tudo passa a ter um significado: consigo entender o verdadeiro sentido do *amor incondicional* dos pais pelos filhos...

Realmente, a atualização deste ano exigiu muito. Foram dois meses trabalhando quase 20 horas por dia. A pequena Manoela não entendia o que estava acontecendo. Desde que ela nasceu estávamos grudados. Falava para ela sobre a minha missão e o compromisso que tenho com os meus ilustres “guerreiros” concurseiros. Não sei se ela entendia... Explicava para ela que o

papai logo voltaria a brincar. Que loucura isso tudo... Que dualidade. Que dificuldade.

Muitas vezes, de madrugada, beijava a Manu e a Má e era como se aquilo me desse mais forças. Quando parecia que não conseguiria mais, eu pensava nas duas... pensava nos meus leitores e no que passam nessa fase tão difícil da vida. Pensava na minha responsabilidade e em cada aluno que vejo renunciando a tantas coisas.

Dizem que todo ser humano tem de *plantar árvores, escrever livros e ter filhos*. De fato, isso tudo já fiz, mas, se soubesse, decididamente, *teria invertido a ordem!*

Escreverei mais livros (essa é a minha missão!) e plantarei mais árvores. Mas, para ser sincero, o que penso mesmo é ter mais um filho.² E aconselho: não deixem que os projetos (muitos profissionais) sejam a única prioridade da vida. Ao lado de pessoas queridas, continuemos a sonhar os sonhos sonhados e, assim, a realizar os projetos idealizados. Sejam felizes! A vida é curta... Obrigado, Manu, por dar sentido a isso tudo. Obrigado, Má, por ter me “dado” a Manu e por estar ao meu lado, sempre acreditando nesse nosso sonho.



UMA NOVA HOMENAGEM ESPECIAL [3](#)

Mais uma vez, gostaria de pedir licença ao meu querido leitor para trazer uma nova e justa homenagem especial...

Quando abri o meu coração em homenagem feita à Manoela, que mudou as nossas vidas, escrevi que, depois de plantar árvores, escrever livros e ter um filho, pensava, mesmo, era em ter mais um filho.

Três anos depois, Max vem ao mundo, trazendo muita alegria e emoção para todos nós.

É impressionante como ele (o nosso querido Macão) olha dentro do meu olho e, no olhar, traduz o sentimento do amor...

Tenho dito que o Max ou a Manu serão os atualizadores do NOSSO Esquematizado®, afinal todos sabem qual é a minha missão de vida (ajudar a realizar sonhos!). Não sei se irão para o mundo do direito... Contudo, tenho certeza de que os dois já têm a absoluta noção do que significa o Esquematizado® em nossas vidas e nas vidas das pessoas, dos “guerreiros concurseiros” do Brasil.

Mesmo pequeno, com menos de um ano de idade, parecia que o Max entendia o que estava acontecendo. Sempre que eu dava uma parada no processo de atualização, ele, com a sua alegria, vinha me beijar e me incentivar.

Nesse período (foram quase 3 meses, trabalhando em média mais de 10 horas por dia), o mais difícil era ter que pedir para a Má segurar as pontas, buscando minimizar a ausência do papai... Em alguns momentos, desesperado em vê-los em casa, durante o mês de janeiro, todos em férias, cheguei a pedir para a Má viajar com eles à praia. Como era complicada a despedida.

E, para piorar, a Manu, já com 3 anos, perguntava: “papai, você vai junto?”. Em uma das várias vezes que falei que não poderia ir, sentei em frente ao computador e “travei”. Tremia... Não conseguia escrever uma linha. Foi quando, incentivado pelos milhares de seguidores das redes sociais, larguei tudo e fui correndo ver a minha “turminha”. Que emoção! Lembro que paramos na estrada para comer pastel. Como era bom estar com eles, o simples fato de estarmos juntos. Foi mesmo energizante aquele final de semana (aqui agradeço aos amigos do Brasil pela força).

Pois bem, como todos sabem, a primeira edição do NOSSO Esquematizado® foi publicada no ano 2000. Já são vários anos de constante e pessoal aperfeiçoamento do trabalho. Já são muitas horas de enclausuramento. Percebi que o Esquematizado®, e não poderia ser de outra maneira, faz parte das nossas vidas. É como se fosse mais um dos nossos “filhos” e, assim, a “turminha” se solidifica: Má, Manu, Max, o NOSSO Esquematizado® e, agora, para completar, o Puffeiro (o cachorrinho que o Papai Noel trouxe para a Manu no último Natal...) e a Chachinha, uma maltês pela qual a Manu se apaixonou durante esse processo das atualizações (Puffeiro tem dormido no meu cunhado, rs.!).

Vivemos o livro e lutamos para que ele continue a servir de ferramenta, ajudando na realização de sonhos... (com certeza, o meu leitor percebe que eu não consigo delegar o trabalho de atualização, por mais dolorido e desgastante que seja...).

E o Max, o que significou nisso tudo? Sem dúvida, a confirmação de que o amor não se divide, mas se soma, se fortalece, se potencializa, enfim se solidifica a cada dia. É impressionante o sentimento que percebo em seu olhar. Macão, você é muito especial e obrigado por ter vindo para somar.

Má, então, novamente e sempre, só tenho que lhe agradecer por ter me “dado” a Manu e o Max e, sempre, por estarmos vivendo esse sonho que é de todos nós. “Turminha”, AMO vocês...



MAIS UMA NOVA HOMENAGEM ESPECIAL

Novamente, gostaria de pedir licença aos meus queridos leitores para trazer *mais uma nova e justa homenagem especial...*

Como muitos perceberam, esta mensagem está sendo escrita para a 19.^a edição, no ano de 2015, mais precisamente, no dia 20.06.2015, data de seu fechamento.

Hoje, o Tommy está fazendo 5 meses de vida. Uma alegria que chegou no meio do trabalho de atualização, tornando este, certamente, mais leve.

Nesses 15 anos de existência do livro, em nenhum momento levei tanto tempo para atualizá-lo. Foram 6 meses. Hoje, neste momento, até me assusto ao ver o Tommy já entendendo tudo com um simples olhar.

Pensando bem, o susto é maior quando vejo que o tempo passou e a vida ao nosso redor não parou. Por isso, sem dúvida, os sentimentos despertados pela chegada da Manu e do Max potencializam-se.

Agora, com 3 filhos e vivendo o livro com eles, tenho certeza de que este compõe as nossas vidas.

Outro dia, nesta reta final, quando disse que tinha acabado o trabalho de revisão, a Manu deu um berro de alegria misturado com alívio: “acabou, Papai?” “Podemos viajar agora?” “Podemos brincar mais?”.

Realmente, é bastante complicado. Mas temos que procurar encontrar um equilíbrio para, juntos, avançarmos neste grandioso projeto de vida, aliás, uma decisão tomada há 15 anos!

Certamente, Manu e Max sabem o valor do Esquematizado®. Certamente,

cada um, do seu modo, sabe que lutamos para ajudar milhares de “guerreiros” do Brasil.

E vou dizer uma coisa: tenho absoluta certeza de que o Tommy, aqui homenageado, também já entendeu tudo. Eu trabalhar em casa, no processo de atualização, faz com que eles se integrem nessa intensa rotina. Muitas vezes, na correria do dia, Tommy ficava no meu colo, vendo-me escrever. Isso mesmo, escrevia enquanto ele estava no meu colo, pois a Má estava com o Max (de 2 anos completados em maio) e a Manu (de 5, feitos no mesmo mês) que também queriam atenção (e olha que tenho de reconhecer a extraordinária ajuda da Má e, também, da Vovó Tina e da Tia Lili).

Esta, sem dúvida, a realidade de muitos, com ou sem filhos, mas sempre encontrando espaço na vida corrida para nutrir o grande sonho.

Devo também dizer que vocês, meus queridos leitores, merecem todo o meu respeito, a minha admiração e consideração, pois sei o que passam. Assim, não consigo delegar o trabalho, que faço artesanalmente, pessoalmente e, por isso, nesta nova fase da vida (claro, sem contar as inúmeras alterações de atos normativos, jurisprudência, códigos etc.), o motivo de termos levado 6 meses para a atualização.

Chegamos ao final satisfeitos com o resultado. A nova edição está com 109 novas páginas e Tommy com 5 meses, justificando e dando razão para essa nossa opção de vida. E tem algo inexplicável: como ele me olha quando estou por perto. Talvez esse seu olhar suplique para que eu termine logo. Mas, no fundo, a paz que me transmite, sem dúvida, reflete a mensagem de que ele sabe a importância disso tudo, especialmente na vida das pessoas.

É isso. Valeu, amigos do Brasil, por tanto apoio que deram nas redes sociais. Tenham certeza de que vocês também foram essenciais. Espero que gostem do trabalho final.

Finalmente, este texto não poderia terminar de outra forma, senão exatamente como aquele que homenageou o Max, mas, agora, naturalmente, *atualizado*: “Má, novamente e sempre, só tenho que lhe agradecer por ter me ‘dado’ a Manu, o Max e o Tommy e, sempre, por estarmos vivendo esse sonho que é de

todos nós. ‘Turminha’ (agora maior - e acho que levei a sério aquela história de *plantar árvores, escrever livros e ter filhos*), AMO vocês...”

À minha **mãe**, exemplo de vida, guerreira da vida,
inspiração espiritual para os que a cercam,
sensibilidade natural, pureza inexplicável
como o nascer do sol, o meu muito obrigado
por ter sempre apoiado os meus projetos intelectuais e
por termos juntos vencido tantos obstáculos...

Ao meu **pai**, que tanto me ensinou, que tanto me orientou,
que com certeza também foi o responsável pelas lições
da vida, obrigado pela força; saiba que o tenho
eternamente em meu coração...

Aos meus irmãos, por tudo o que representam e
pelo exemplo de garra, perseverança e alegria de vida...

Ao **Felipinho** e ao **Rafinha**, meus sobrinhos, pela renovação de todos esses
sentimentos...

A todos vocês dedico este trabalho.

A vocês, **Má**, **Manu**, **Max** e **Tommy**,
por tudo o que significam em minha vida,
alegando-a, energizando-a, abençoando-a;
pela pureza, preciosidade, ternura,
meiguice e amor;
por tanta força e positividade depositadas
neste meu projeto de vida;
com carinho, o meu eterno agradecimento.



AGRADECIMENTOS

Todos, com certeza, tiveram um papel fundamental para que este trabalho se concretizasse, sendo muitos os nomes que deveriam ser relacionados para não incorrer em injustiças.

Devo, contudo, lembrar algumas pessoas que, com certeza, influenciaram muito o meu desenvolvimento acadêmico.

Ada Pellegrini Grinover, exemplo de jurista, exemplo de doutrinadora, exemplo de cientista do direito, exemplo de pensadora, pessoa a quem devo o eterno agradecimento pela oportunidade de desenvolver os estudos de pós-graduação (**mestrado** e **doutorado**) na Faculdade de Direito da USP e pelo apoio neste trabalho conjuntamente com o projeto de pesquisa, encontrando, ainda, dentre tantos afazeres, o precioso tempo para apresentá-lo à comunidade acadêmica.

Antonio Carlos Marcato, ex-membro do MP, Desembargador aposentado e agora advogado. Sem dúvida, poucos têm essa “tríplice” experiência que o mestre, com generosidade, compartilha, divulgando o seu conhecimento, ensinando e encantando.

Damásio de Jesus, mestre de todos nós, modelo de paixão e devoção pela ciência do direito, ensinando-nos que o aprendizado não tem limites ou fronteiras: seremos eternos estudiosos, pelo resto de nossas vidas.

Leda Pereira Mota, amiga de sempre que, nos bancos acadêmicos, fez nascer em mim a paixão pelo Direito Constitucional quando me convidou para auxiliá-la nas aulas de seminário na PUC/SP, espaço utilizado em conjunto com os alunos, como verdadeiro “laboratório experimental”, discutindo diversas questões sobre

a matéria. Você será nossa eterna mestra!

Maria Helena Diniz, pela amizade sincera e por ter mostrado para mim e, creio, para todos os que com ela convivem o exemplo de vida e de ser humano, bem como de grande estudiosa do direito.

Agradeço ao *Damásio Educacional*, pela credibilidade conferida a este estudo e por acreditar nesse grande sonho, alimentando-o diariamente.

Agradeço, também, ao *Marcato Cursos Jurídicos*, por tantas oportunidades e alegrias vividas no passado.

Agradeço ao *ProOrdem — Centro de Estudos Jurídicos*, nas pessoas de *Marco Antônio Clauss*, *Joana D’Arc Alves Trindade* e *Clerice Pires*, pela amizade e pelo apoio que, no início, depositaram neste trabalho.

Sinceros são os meus agradecimentos à *OAB/SP*, que, apoiando o desenvolvimento dos advogados, abriu as portas para que eu pudesse apresentar-me em palestra proferida na *OAB/Pinheiros*. Aproveito este espaço para declarar a minha eterna gratidão a toda a comunidade pinheirense, na pessoa de seu ex-Presidente, o amigo *José Vicente Laino*, exemplo humano de pessoa e profissional.

Gostaria de agradecer o carinho que tenho recebido em todo o Brasil nos cursos e palestras, com os quais muito aprendi.

Aliás, não poderia deixar de expressamente agradecer a dois grandes mestres. Em primeiro lugar (*ladies first...*), à amiga *Noêmia Garcia Porto*, por tudo e por ter-me dado a honra de dialogar sobre grandes temas do direito constitucional. Em segundo, ao grande mestre *Cássio Juvenal Faria*, por tanta credibilidade depositada neste estudo, o que, para mim, é um grande orgulho! Simplesmente, o meu muitíssimo obrigado...

Tio Beto, Tia Christina, Li e Bruno, obrigado por estarem juntos neste meu projeto de vida.

Tio Cláudio, Tia Marly, Vó Olguinha, Cris, Clau, Fábio... obrigado por termos pensado juntos a nova “cara” do livro.

Tia Márcia, Débora, Thaís e família, obrigado por me apoiarem desde o começo.

Ao Igor, meu mais novo comprador... ele só tinha 5 anos e, utilizando o cartão da minha esposa, comprou o livro no *saraiva.com*!

Fau e Guto, Tia Etra, Ailton, Tio Eduardinho, Duca, Tia Jussara, Fabinho, Leny e Nice, pela energia da Bahia, muitíssimo obrigado.

Lembro, ainda, *Armando Casimiro Costa Filho* e todos da *LTr Editora*, que, logo no primeiro contato, acreditaram em mim, viabilizando a realização deste sonho, sendo responsáveis pelas cinco primeiras edições desta obra.

Em igual sentido, os meus profundos agradecimentos a *Vauledir Ribeiro Santos* e a todos da *Editora Método*, que, empenhados na manutenção do grande sonho, deram importante projeção nacional ao trabalho e lutaram ao meu lado da 6.^a até a 11.^a edição.

A partir da 12.^a edição tive a honra e o privilégio de unir forças com a querida **SARAIVA**, que, desde o início, também acreditou neste grande sonho. Em nome de *Jorge Eduardo Saraiva, Ruy Mendes Gonçalves, José Luiz M. A. de Próspero, Antonio Luiz de Toledo Pinto, Nilson Lepera, Luiz Roberto Curia, Jônatas Mello, Lígia Alves, Maria Lúcia Godoy, Clarissa B. Maria, Rubens F. Odagima, Luiz Facchini, Sandra Bensadon, Gisele Guerra, Valéria Zanocco, Henrique H. Garcia, Arlindo Meira, André Pereira*, toda a comprometida e profissional *Equipe de Divulgação*, eu só tenho a agradecer a **todos** que de um modo ou de outro se envolveram neste projeto.

A partir da 18.^a edição estou tendo a alegria e honra de trabalhar ao lado dos antigos e de novos colegas, todos muito empolgados e focados no atual momento do **Esquematizado**®. Já maduro e firme no mercado editorial, agora com o sucesso da *Coleção Esquematizado*®, esperamos continuar cumprindo o nosso papel. Assim, obrigado por terem contribuído para o desafio: continuar com a excepcional aceitação nacional (não é fácil manter o livro “vivo”) e, sempre, na busca da confiança de novos e fiéis leitores. Assim, o meu agradecimento para *Jorge Saraiva Neto, Maurício Pereira Fanganiello, Ronyse Avelino Pacheco, Ilaine Cristina de Melo* e, na linha de frente do editorial, *Thais Camargo Rodrigues, Deborah Caetano de Freitas Viadana e Eveline Gonçalves Denardi*.

SARAIVA, simplesmente **OBRIGADO** por tudo. Estou muito feliz e espero que os meus queridos leitores aprovem a nova fase do *Esquematizado®*, casamento novo, parceria de sucesso, juntos na luta pelos grandes sonhos!

Ainda, sou e serei eternamente grato a *Roseli* e *Rose* e toda a equipe da *Know-how Editorial*, pelo profissionalismo, comprometimento e arte de editar. Vocês realmente “sabem como” produzir um livro de sucesso, inovando o mercado editorial.

Não posso deixar de agradecer aos *amigos, professores, operadores do direito*, vários leitores das áreas não jurídicas, pela divulgação do presente trabalho, por suas sugestões e especialmente pela forte acolhida das edições anteriores!

Por fim, aos *alunos, candidatos aos “concursos da vida”*, minha fonte inspiradora diária para sempre continuar estudando e com eles aprendendo: minha realização como ser humano.

A todos, o meu muito obrigado.

O autor



NOTA DO AUTOR À 19.^a EDIÇÃO

Chegamos à **19.^a edição**, com muito trabalho e constante preocupação com o conteúdo e a precisão das informações.

O texto está adequado e ampliado considerando o Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), as atuais 53 súmulas vinculantes (STF), 88 emendas constitucionais e principais decisões do STF até a data de fechamento desta edição, qual seja, 20.06.2015. Várias leis infraconstitucionais também foram apreciadas, destacando-se o *Estatuto Geral das Guardas Municipais* (Lei n. 13.022/2014) e o *Estatuto da Metrópole* (Lei n. 13.089/2015). Evidenciamos, ainda, as resoluções do CNJ e do CNMP, bem como alguns aspectos importantes do *RISTF*. Temas novos foram introduzidos, como, dentre vários, apenas para se ter um exemplo, a interessante discussão sobre o legado da experiência pioneira da Islândia: *crowdsourced Constitution*.

A maior parte dos textos foi escrita em Santos, a querida “Veneza brasileira”, ou, por que não, a querida “Miami brasileira”... O trabalho era intenso. Não podia parar, sempre atualizando e lutando em nome dos sonhos dos meus amigos “Guerreiros Concurseiros”. Muitas madrugadas ao lado de queridos seguidores das redes sociais que me ajudavam a não desistir... Que dificuldade! Descontando o tempo do nascimento do Tommy (cf. “mais uma nova homenagem especial”), foram exatos **6 longos meses** trabalhando diariamente. Nesses 15 anos de existência do livro, nunca ficamos tanto tempo em uma atualização. Isso mesmo, 6 meses de muito trabalho. Não é fácil manter o livro “vivo”!

O resultado de tanto esforço: **109 novas páginas** de imprescindível conteúdo!

Muita jurisprudência nova, muitos temas novos, muitas alterações normativas.

Sem dúvida, os vários *e-mails* que chegam de todo o Brasil e as sugestões recebidas em cursos e palestras têm servido de importante fonte para o enriquecimento deste trabalho. Assim, agradeço aos amigos deste nosso grande país.

Com importantes comentários, ricas sugestões e discussões, novamente e sempre, ao amigo Leandro Hissa Dahi, serei eternamente grato. É impressionante como o Leandro consegue, a cada nova edição, ajudar a melhorar o nosso *Esquematizado*®!

Li, Bruno, Tia Christina, Tio Barreto e, claro, Má, obrigado por terem minimizado o sentimento da Manu, do Max e do Tommy, que não entendiam a minha ausência... De fato, sem vocês me ajudando, eu não teria conseguido implementar essa árdua tarefa que é a atualização do livro.

A loucura disso tudo é chegar ao final desse trabalho de atualização e o Tommy já estar com 5 meses! É mesmo tudo muito impressionante.

Outrossim, durante todo esse tempo, os cursos que já ministramos na TV Justiça (“Aula Magna”, “Saber Direito”, “Apostila”) e em alguns tribunais (cursos de capacitação interna) serviram para percebermos as tendências da jurisprudência, que se mostram extremamente importantes àqueles que se preparam para concursos públicos.

Nesse particular, declaradamente, **agradecemos** e **homenageamos** o extraordinário trabalho do setor de jurisprudência do **STF**, notadamente a equipe responsável pelo **“Notícias”**, pelo **“Informativos”** e pelo notável **“A Constituição e o Supremo”**, compêndio eletrônico lançado pelo STF e desenvolvido pelas *Secretarias de Documentação e de Informática*, em cumprimento a uma das promessas do Ministro Nelson Jobim na Presidência; no caso, a de facilitar acesso rápido e preciso às informações, verdadeiro dever das fontes.

Indispensável, outrossim, a análise do trabalho de informações do **STJ** e dos sites da **Câmara** e do **Senado Federal**.

Para esta nova edição, o processo de pesquisa foi intenso, inclusive com

aumento de assuntos na parte teórica. Vários temas foram incorporados ao trabalho, destacando-se importantes mudanças na jurisprudência do STF (“viragens jurisprudenciais”), especialmente em razão da nova composição da Corte.

Foram **6 meses** enclausurado. Algo impressionante... Não imaginava que levaria tanto tempo, afinal, para a edição anterior eu já havia ficado mais de 2 meses ininterruptos no processo de revisão. Muitas madrugadas, e o que me alimentava eram os meus milhares de queridos seguidores do Brasil (*Twitter*, *Fan Page* — *Facebook*, *Instagram*), que, constantemente, mandavam mensagens de apoio e incentivo, sem contar, muitas vezes, a participação ativa de muitos no processo de atualização (por isso, faço questão de tratar o livro como o “**Nosso Esquematizado®**”). Essa injeção de ânimo e a preocupação em sempre trazer o melhor para o meu querido leitor me ajudavam a continuar trabalhando, mesmo tendo que “virar” várias noites na reta final!

A seguir, apontamos as principais mudanças inseridas nesta 19.^a edição, revista, atualizada e ampliada, bem como em conformidade com a **reforma ortográfica**, com a **tendência dos concursos públicos do Brasil** e a **jurisprudência do STF**, buscando facilitar a vida daquele ilustre leitor que possui as edições anteriores:

Capítulo 1 — algumas correções foram feitas, sem alteração substancial do texto. Questões foram inseridas.

Capítulo 2 — a parte teórica foi ampliada, destacando-se: a) a nova discussão sobre o papel das Constituições; b) o legado da experiência pioneira da Islândia: *crowdsourced Constitution*. Questão foi inserida.

Capítulo 3 — o texto foi revisto e atualizado, destacando-se a decisão sobre o poder de investigação do Ministério Público. Questões relevantes foram acrescentadas.

Capítulo 4 — a parte teórica foi revista. Questões foram introduzidas.

Capítulo 5 — a parte teórica foi atualizada de acordo com novos julgados do STF. Questões foram introduzidas.

Capítulo 6 — a parte teórica foi revista e adequada a importantes decisões

fixadas pelo STF, inclusive com mudança de entendimento, bem como as profundas alterações introduzidas pelo CPC/2015. Dentre os vários temas, destacamos: a) novas perspectivas sobre o vício de decoro parlamentar; b) importante discussão em relação à cláusula de reserva de plenário no STF; c) julgamento final da RCL 4.335 não acatando, a Corte, a tese da abstrativização do controle difuso; d) análise da temática da eficácia expansiva das decisões, especialmente à luz do CPC/2015; e) destaque à amplitude da S. 343/STF, tendo por parâmetro o RE 590.809 (j. 22.10.2014), bem como o CPC/2015; f) aprimoramento do estudo sobre as omissões normativas.

Capítulo 7 — a parte teórica foi adequada às novas emendas constitucionais, destacando-se a **EC n. 85/2015** e a **EC n. 87/2015**. Ainda, analisamos importantes alterações legislativas como o *Estatuto da Metrópole* (Lei n. 13.089/2015). Ampliamos o texto, destacando relevante jurisprudência sobre a competência federativa para legislar, ressaltando-se o caso particular da queima da palha da cana-de-açúcar (RE 586.224), bem como novas súmulas vinculantes. Questões foram introduzidas.

Capítulo 8 — o texto foi revisto e novas questões inseridas.

Capítulo 9 — a parte teórica foi revista e totalmente modificada em relação às importantes decisões do STF e mudanças de entendimento.

Capítulo 10 — a matéria foi revista de acordo com importantes definições determinadas pela jurisprudência do STF.

Capítulo 11 — a parte teórica foi atualizada de acordo com jurisprudência do STF, inclusive as súmulas vinculantes (a última de n. 53, aprovada em 18.06.2015), bem como as reformas constitucionais, destacando-se, para se ter um exemplo, a **EC n. 80/2014**. Novos temas foram introduzidos e debatidos, como a **EC n. 88/2015** e a **ADI 5.316** (“PEC da Bengala”).

Capítulo 12 — o texto foi **atualizado** de acordo com importantes decisões do STF, bem como no tocante à Defensoria Pública, conforme a EC n. 80/2014. Importantes assuntos novos debatidos pela Corte foram introduzidos.

Capítulo 13 — o texto foi reestruturado e adequado à jurisprudência do STF. Houve importante modificação introduzida pela **EC n. 82/2014** (segurança viária

e a carreira dos agentes de trânsito), bem como normativa, pela **Lei n. 13.022/2014** que dispôs sobre o *Estatuto Geral das Guardas Municipais*.

Capítulo 14 — o texto foi ampliado em relação a importantes decisões do STF, bem como novos temas teóricos.

Capítulo 15 — o texto foi atualizado de acordo com a jurisprudência, destacando-se, para um exemplo, a viragem em relação ao prazo prescricional de cobrança do FGTS. Questões foram introduzidas.

Capítulo 16 — a parte teórica foi revista e atualizada, destacando-se o caso da **extradição ativa** do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, condenado no processo do mensalão (AP 470).

Capítulo 17 — o texto foi revisto e atualizado.

Capítulo 18 — o texto foi adequado à jurisprudência da Suprema Corte, havendo relevante modificação de entendimento em relação à fidelidade partidária dos candidatos eleitos pelo sistema majoritário (Chefes do Executivo e Senadores da República).

Capítulo 19 — o texto foi revisto e atualizado, destacando-se, além de vasta jurisprudência do STF, a **EC n. 78/2014** (“Soldados da Borracha”) e a **EC n. 85/2015**. Novas perspectivas foram lançadas, como a discussão sobre o **infanticídio indígena**.

Capítulo 20 — o texto foi revisto e adequado de acordo com a jurisprudência do STF.

Capítulo 21 — o texto foi revisto e atualizado.

Capítulo 22 — o texto foi atualizado de acordo com a jurisprudência do STF.

Em relação aos **concursos públicos**, estamos fazendo — e fizemos — amplo acompanhamento dos temas mais exigidos em todo o País, aprofundando o texto teórico, quando necessário. Outrossim, realizamos minucioso estudo dos editais dos principais certames. Ampliamos, também, a análise dos concursos da área fiscal (ESAF, CESPE/UnB, FCC, Instituto Cidades, FGV e outras bancas organizadoras) e constatamos que as provas se encontram em um nível extremamente exigente, muitas, inclusive, superiores a algumas da área jurídica

(por exemplo, Analista de Finanças e Controle — AFC; Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil; Analista de Controle Externo do TCU; Analista Tributário da Receita Federal do Brasil; Analista de Comércio Exterior do MDIC; Analista do Banco Central, entre outras). Observamos, ainda, que as provas de analista judiciário, técnico judiciário, escrivão de polícia, oficial de justiça e agente administrativo tiveram um incremento em termos de dificuldade.

Esperamos que esta obra, em sua nova edição, continue ajudando os colegas e, mais uma vez, aguardamos as críticas e sugestões.

Estamos trabalhando fortemente para o constante aprimoramento do “nosso” *Esquematizado*®, sempre orando para que todos os ilustres concurseeiros, honestos e batalhadores, realizem o seu “sonho dourado”.

Amigo, amiga, certamente, **2015** será o seu grande ano! Contem comigo!

Eternamente grato...

São Paulo, outono de 2015

(atualizações até as 8 horas do dia 20.06.2015)

Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP

E-mail: pedrolenza@terra.com.br

Twitter: <https://twitter.com/pedrolenza>

Instagram: <http://instagram.com/pedrolenza>

Facebook: <https://www.facebook.com/pedrolenza>

Vídeos: <https://www.youtube.com/pedrolenzaoficial>

Saraiva: <http://www.editorasaraiva.com.br/esquematizado>



PREFÁCIO

Esta obra, como apontado pela Professora *Ada Pellegrini Grinover* na apresentação deste trabalho, busca auxiliar os candidatos a concursos públicos e provas de faculdade, servindo, ainda, como manual de consulta para os operadores do Direito.

Percebendo a dificuldade dos alunos na matéria, tentei esquematizar os grandes temas do Direito Constitucional, não só em linguagem direta como também por meio de um “formato” mais conveniente, propiciando uma leitura mais dinâmica e, ao mesmo tempo, estimulante.

A partir da 12.^a edição, junto com a SARAIVA, o projeto gráfico foi totalmente modificado. Recorremos ao uso de cores (**azul**) para facilitar ainda mais o estudo dos *guerreiros concurseiros*. Espero que aprovelem e, assim, aguardo os comentários!

Nesse espírito, busquei determinar o posicionamento da *doutrina*, apontando a corrente que prevalece e indicando o entendimento do *Supremo Tribunal Federal* sobre a matéria. Por meio de pesquisa minuciosa, procurei trazer tudo de mais atualizado que há sobre o assunto, contando com o relevante instrumento que é a Internet.

Devo observar que, em decorrência do objetivo deste trabalho, qual seja, **auxiliar os candidatos a provas e concursos públicos**, sempre que percebia divergências na matéria, sem deixar de apontar o meu posicionamento, indiquei qual deveria ser a linha adotada nas provas preambulares.

Essa minha perspectiva está consagrada no art. 17, § 1.º, da *Resolução n. 14, de 06.11.2006, do CNMP — Conselho Nacional do MP*, que, ao dispor sobre as

Regras Gerais Regulamentares para o concurso de ingresso na carreira do MP brasileiro, estabeleceu: “a prova preambular **não** poderá ser formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais. As opções consideradas corretas deverão ter embasamento na **legislação**, em **súmulas** ou **jurisprudência** dominante dos Tribunais Superiores”.

Em igual medida, estabelece o art. 33 da *Resolução n. 75, de 12.05.2009, do CNJ — Conselho Nacional de Justiça*: “as questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, **necessariamente**, a resposta reflita a **posição doutrinária dominante** ou a **jurisprudência pacificada** dos Tribunais Superiores”.

Tentando, ainda, implementar as “armas” para esta verdadeira “guerra intelectual”, além de me valer da linguagem clara e direta, bem como da forma de apresentação do trabalho (quadros, esquemas, itens e subitens), no final de cada capítulo teórico procurei ilustrar o assunto trazendo **provas de concursos públicos e algumas questões de minha própria autoria**, facilitando, assim, a percepção pelo candidato das matérias que mais são questionadas em cada um dos temas do Direito Constitucional.

Creio que o objetivo foi atingido, recompensando o esforço empreendido neste trabalho.

Devo declarar que imperfeições eventualmente existirão, motivo pelo qual estarei sempre aberto para discussões e sugestões.

Da minha parte, tentei, ao máximo, recrutar todas as “armas” que auxiliassem os alunos e candidatos a atingir os seus objetivos: a vocação de uns é para a advocacia, a de outros, para o MP, a de outros, para a Magistratura, a de outros, ainda, para os demais concursos, sejam da área jurídica ou não jurídica; por fim, há os que precisam de uma consulta rápida sobre determinado assunto, relacionado à sua vida profissional.

Saibam que sempre estarei à procura de elementos para ajudá-los nesta fase difícil de suas vidas. **Nunca desistam!** Sejam sempre fortes! Tenho certeza, e sempre falo para os meus alunos, que todos podem... só depende de vocês.

Confio plenamente em cada um. Vocês só precisam acreditar em si e se concentrar ao máximo em seus objetivos, e tenho fé em Deus que sempre conseguirão o que buscam.

No final, quando olharem para trás e disserem que valeu o esforço, que atingiram o que buscavam, essa alegria, tenham certeza, será a minha maior recompensa, e isso bastará para que eu olhe para trás e também diga: “Pedro, valeu a pena tanto esforço neste trabalho...”.

Agora, vamos à luta. *Muito boa sorte neste seu projeto de vida. Chamem-me para a posse!*

São Paulo, outono de 2015

Pedro Lenza



APRESENTAÇÃO À 1.^a EDIÇÃO

É com grande satisfação que apresento o livro do jovem e promissor mestrando da Faculdade de Direito da USP, *Pedro Lenza*, intitulado “Direito Constitucional Esquematizado”. Escrita numa linguagem clara e direta, a obra destina-se, declaradamente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, sem eximir-se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição.

Da leitura amena surge um livro “fácil”, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais maduros, sobretudo no campo do direito.

Penso, assim, que a obra será de grande valia para a comunidade jurídica. Só resta desejar a seu jovem autor todo o êxito que merece.

São Paulo, 24 de novembro de 1999

Ada Pellegrini Grinover

(NEO)CONSTITUCIONALISMO

■ 1.1. ALOCAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL

■ 1.1.1. A classificação em “ramos do direito”

Antes de tratarmos do movimento que recebeu o nome de “constitucionalismo”, faremos uma ponderação inicial, lembrando que o *direito constitucional* costuma ser alocado dentro do ramo do direito público, destacando-se por seu objeto e princípios fundamentais orientadores de sua aplicação.

José Afonso da Silva observa que o *direito constitucional* “configura-se como **Direito Público fundamental** por referir-se diretamente à *organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política*”.¹

Apesar de colocarmos o *direito constitucional* dentro do ramo do direito público (fundamental), devemos alertar o leitor que, modernamente, vem sendo dito que o direito é **uno e indivisível, indecomponível**. O direito deve ser definido e estudado como um grande **sistema**, em que tudo se harmoniza no conjunto. A divisão em ramos do direito é meramente didática, a fim de facilitar o entendimento da matéria, vale dizer: questão de **conveniência acadêmica**.

Aceitando a classificação dicotômica (público e privado), apenas para fins didáticos, dentro do **direito público** poderemos alocar, também (destacando-se

a particularidade **fundamental** do direito constitucional), o direito administrativo, o urbanístico, o ambiental, o tributário, o financeiro, o econômico, o penal, o processual, o internacional etc., ao contrário do direito civil e do comercial, que, historicamente, preencheriam a categoria do **direito privado**.

Referida classificação dicotômica pode ser atribuída a **Jean Domat** (afastando-se daqueles que a imputam ao Direito Romano), que foi quem separou, pela primeira vez, as **leis civis** das **leis públicas** e cuja obra influenciou a elaboração do **Código Napoleão** de 1804, despertando a denominada “**Era da Codificação**”, que conferiu ao Código Civil a natureza de verdadeira “**constituição privada**”, disciplinando as relações particulares, as regras sobre família, a propriedade, o estado civil, a capacidade etc. Surgia então a ideia do **dogma da completude**, ou seja, de que os Códigos continham toda a regulamentação das relações privadas, devendo o juiz simplesmente aplicá-las.²

Essa perspectiva de codificação do direito civil como regulador das relações privadas é fortalecida pela principiologia do **liberalismo clássico**, que enalteceu a ideia de **liberdade meramente formal** perante a lei e de **não intervenção do Estado** (direitos de **primeira “geração”**, ou, mais tecnicamente, de **primeira “dimensão”**) (*absenteísmo estatal*), tema que será retomado no estudo dos direitos fundamentais (cf. *item 14.2* deste trabalho).

Em outro momento, além da classificação dicotômica em ramo de direito público e de direito privado, a evolução do Estado liberal para o **Estado social de direito** faz surgir a necessidade de se reconhecer, ao lado da dicotomia, a categoria dos **direitos sociais**, cujas normas de direito do trabalho e de direito previdenciário expressam a manifestação de um Estado prestacionista, intervencionista e realizador da chamada **justiça distributiva** (esses novos direitos, chamados de **segunda geração** ou **dimensão**, surgem, pela primeira vez, na Constituição brasileira de 1934), tendo como marco a Revolução Industrial.

O texto de 1988, por sua vez, muito embora já tivesse sido insinuado no texto de 1946 e na Carta de 1967, consagra a proteção aos direitos de **terceira**

geração ou **dimensão**, marcados pelo lema da **solidariedade** ou **fraternidade**, evidenciando, assim, os direitos transindividuais.³

■ 1.1.2. A superação da dicotomia “público-privado” — constitucionalização do direito privado

Avançando, por outro lado, modernamente, sobretudo em razão da evidenciação de novos direitos e das transformações do Estado (de autoritário/absolutista para liberal e de liberal para social, podendo-se, inclusive, falar em Estado pós-social de direito), cada vez mais se percebe uma forte influência do **direito constitucional** sobre o **direito privado**.

Sob essa perspectiva, especialmente diante do princípio da **dignidade da pessoa humana**, fundamento da República Federativa do Brasil e **princípio-matriz** de todos os direitos fundamentais (art. 1.º, III, da CF/88), parece mais adequado, então, falar em um **direito civil-constitucional**, estudando o direito privado à luz das regras constitucionais e podendo, inclusive, em muitos casos, reconhecer a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas, tema que será mais bem estudado no *item 14.8* deste trabalho (**eficácia horizontal dos direitos fundamentais**).⁴

Essa situação, qual seja, a superação da rígida dicotomia entre o público e o privado, fica mais evidente diante da tendência de **descodificação** do direito civil, evoluindo da concentração das relações privadas na codificação civil para o surgimento de vários **microssistemas**, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Locações, a Lei de Direito Autoral, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei de Alimentos, a Lei da Separação e do Divórcio etc.

Todos esses microssistemas encontram o seu fundamento na Constituição Federal, norma de validade de todo o **sistema**, passando o direito civil por um processo de **despatrimonialização**.⁵

Portanto, apesar da “suposta” utilidade didática, parece adequado **não mais falarmos em ramos do direito**, e sim em um verdadeiro escalonamento

verticalizado e hierárquico das normas, apresentando-se a Constituição como **norma de validade** de todo o sistema, situação essa decorrente do princípio da **unidade do ordenamento** e da **supremacia da Constituição** (**força normativa da Constituição** — Konrad Hesse).⁶

Fala-se, então, em uma necessária e inevitável **releitura dos institutos**, notadamente os de direito civil (e privado), sob a ótica constitucional, conforme o quadro a seguir:⁷

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (Princípio-Matriz)
■ Direito Civil Constitucional ■ Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais ■ Descodificação do Direito Civil ■ Microsistemas ■ Despatrimonialização do Direito Civil

■ 1.2. CONSTITUCIONALISMO

■ 1.2.1. Conceito

Canotilho identifica vários constitucionalismos, como o inglês, o americano e o francês, preferindo falar em “movimentos constitucionais”. Em seguida, define o constitucionalismo como uma “... teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma *técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos*. O conceito de constitucionalismo transporta,

assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma *teoria normativa da política*, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo”.⁸

Kildare Gonçalves Carvalho, por seu turno, vislumbra tanto uma perspectiva **jurídica** como **sociológica**: “... em termos jurídicos, reporta-se a um sistema normativo, enfeixado na Constituição, e que se encontra acima dos detentores do poder; sociologicamente, representa um movimento social que dá sustentação à limitação do poder, inviabilizando que os governantes possam fazer prevalecer seus interesses e regras na condução do Estado”.⁹

André Ramos Tavares estabelece quatro sentidos para o constitucionalismo:

“... numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, **limitar o poder arbitrário**. Numa segunda acepção, é identificado com a imposição de que haja cartas constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa terceira acepção possível, para indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. Numa vertente mais restrita, o constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional de um determinado Estado”.¹⁰

Partindo, então, da ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição, avança-se no sentido de que os textos constitucionais contêm regras de **limitação ao poder autoritário** e de **prevalência dos direitos fundamentais**, afastando-se da visão opressora do antigo regime.

■ 1.2.2. Evolução histórica

A História da Europa pode ser dividida, sem muita preocupação teórica, em quatro grandes “eras”: **Idade Antiga** (até o século V — tomada do Império Romano do Ocidente pelos povos bárbaros — 476 d.C.); **Idade Média** (século V até o fim do Império Romano do Oriente, com a *queda de Constantinopla*, no século XV — 1453 d.C.); **Idade Moderna** (1453-1789 — Revolução Francesa); **Idade Contemporânea** (1789 até os dias atuais).

Sem se preocupar com a análise das referidas “eras”, Canotilho, entre tantas

distinções, estabelece, mais simplificada, apenas dois grandes **movimentos constitucionais**: o constitucionalismo **antigo** e o **moderno**, caracterizando-se este último como “... o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII, questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de *domínio político*, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma forma de ordenação e fundamentação do poder político”.¹¹

Isso posto, passemos a analisar, brevemente, a evolução histórica do constitucionalismo.

■ 1.2.2.1. *Constitucionalismo durante a Antiguidade*

Analisando a **Antiguidade clássica**, Karl Loewenstein identificou, entre os **hebreus**, timidamente, o surgimento do constitucionalismo, estabelecendo-se no Estado teocrático limitações ao poder político ao assegurar aos profetas a legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos.¹²

Refere o autor, ainda, mais tarde, no século V a.C., a experiência das **Cidades-Estados gregas** como importante exemplo de democracia constitucional, na medida em que a **democracia direta**, particular a elas, consagrava “... o único exemplo conhecido de sistema político com plena identidade entre governantes e governados, no qual o poder político está igualmente distribuído entre todos os cidadãos ativos”.¹³

■ 1.2.2.2. *Constitucionalismo durante a Idade Média*

Durante a **Idade Média**, a **Magna Carta de 1215** representa o grande marco do constitucionalismo medieval, estabelecendo, mesmo que formalmente, a proteção a importantes direitos individuais.

■ 1.2.2.3. Constitucionalismo durante a Idade Moderna

Na Idade Moderna, destacam-se: o *Petition of Rights*, de 1628; o *Habeas Corpus Act*, de 1679; o *Bill of Rights*, de 1689; e o *Act of Settlement*, de 1701.¹⁴

Nessa linha, além dos **pactos**, há o que a doutrina chamou de **forais** ou **cartas de franquia**, também voltados para a proteção dos direitos individuais. Diferenciam-se dos pactos por admitir a participação dos súditos no governo local (elemento político).

Os **pactos** e **forais** ou **cartas de franquia**, documentos marcantes durante a Idade Média, buscavam resguardar **direitos individuais**. Alerta-se, contudo, que se tratava de direitos direcionados a determinados homens, e não sob a perspectiva da universalidade.

■ 1.2.2.4. Constitucionalismo norte-americano

Outro ponto nessa evolução do **constitucionalismo** foram os chamados **contratos de colonização**, marcantes na história das colônias da América do Norte.

Como anota Ferreira Filho, “chegados à América, os peregrinos, mormente puritanos, imbuídos de igualitarismo, não encontrando na nova terra poder estabelecido, fixaram, por *mútuo consenso*, as regras por que haveriam de governar-se. Firma-se, assim, pelos chefes de família a bordo do *Mayflower*, o célebre ‘*Compact*’ (1620); desse modo se estabelecem as *Fundamental Orders of Connecticut* (1639), mais tarde confirmadas pelo rei Carlos II, que as incorporou à Carta outorgada em 1662. Transparece aí a ideia de estabelecimento e organização do governo pelos próprios governados, que é outro dos pilares da ideia de Constituição”.¹⁵

Nesse sentido é que Kildare identifica como indícios do constitucionalismo na América, além dos referidos “contratos de colonização” (*Compact* e as *Fundamental Orders of Connecticut*), a *Declaration of Rights* do Estado de

Virgínia, de 1776, seguida pelas Constituições das ex-colônias britânicas da América do Norte, Constituição da Confederação dos Estados Americanos, de 1781. [16](#)

■ 1.2.2.5. *Constitucionalismo moderno (durante a Idade Contemporânea)*

Chegamos, então, ao **constitucionalismo moderno**, em que predominam as **constituições escritas** como instrumentos para conter qualquer arbítrio decorrente do poder.

Dois são os marcos históricos e formais do constitucionalismo moderno: a **Constituição norte-americana de 1787** e a **francesa de 1791** (que teve como preâmbulo a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789), movimento este deflagrado durante o Iluminismo e concretizado como uma contraposição ao absolutismo reinante, por meio do qual se elegeu o **povo** como o **titular legítimo do poder**.

Podemos destacar, nesse primeiro momento, na concepção do **constitucionalismo liberal**, marcado pelo liberalismo clássico, os seguintes valores: individualismo, absentismo estatal, valorização da propriedade privada e proteção do indivíduo. Essa perspectiva, para se ter um exemplo, influenciou profundamente as Constituições brasileiras de 1824 e 1891.

Conforme falamos, a concepção liberal (de valorização do indivíduo e afastamento do Estado) gerará **concentração de renda e exclusão social**, fazendo com que o Estado passe a ser chamado para evitar abusos e limitar o poder econômico.

Evidencia-se, então, aquilo que a doutrina chamou de segunda geração (ou dimensão) de direitos e que teve como documentos marcantes a Constituição do México de 1917 e a de Weimar de 1919, influenciando, profundamente, a Constituição brasileira de 1934 (**Estado Social de Direito**).

■ 1.2.2.6. *Constitucionalismo contemporâneo (durante a Idade Contemporânea) “antenado” com a ideia de “constitucionalismo*

globalizado”

O **constitucionalismo contemporâneo** está centrado naquilo que Uadi Lammêgo Bulos chamou de “**totalitarismo constitucional**, consectário da noção de **Constituição programática**”, e que tem como bom exemplo a Constituição brasileira de 1988.¹⁷

Fala-se em “**totalitarismo constitucional**” na medida em que os textos sedimentam um importante **conteúdo social**, estabelecendo normas programáticas (metas a serem atingidas pelo Estado, programas de governo) e realçando o sentido de **Constituição dirigente** defendido por Canotilho.

Contudo, partindo dessa concepção de normas programáticas, André Ramos Tavares, apoiado no pensamento de Dromi (*vide item 1.2.2.7 a seguir*), enaltece o **constitucionalismo da verdade** e, assim, em relação às normas programáticas, identifica duas categorias:

“normas que jamais passam de programáticas e são praticamente inalcançáveis pela maioria dos Estados”;

“normas que não são implementadas por simples falta de motivação política dos administradores e governantes responsáveis”.

Consoante alerta Tavares, “as primeiras precisam ser erradicadas dos corpos constitucionais, podendo figurar, no máximo, apenas como objetivos a serem alcançados a longo prazo, e não como declarações de realidades utópicas, como se bastasse a mera declaração jurídica para transformar-se o ferro em ouro. As segundas precisam ser cobradas do Poder Público com mais força, o que envolve, em muitos casos, a participação da sociedade na gestão das verbas públicas e a atuação de organismos de controle e cobrança, como o Ministério Público, na preservação da ordem jurídica e consecução do interesse público vertido nas cláusulas constitucionais”.¹⁸

Essa concepção de dirigismo estatal (de o texto fixar regras para dirigir as ações governamentais) tende a evoluir para uma perspectiva de **dirigismo comunitário**, ideia também vislumbrada por André Ramos Tavares ao falar em uma fase atual do **constitucionalismo globalizado**, que busca difundir a perspectiva de proteção aos direitos humanos e de propagação para todas as

nações. [19](#)

Destacamos, ainda, uma concepção de proteção aos direitos de **fraternidade** ou **solidariedade**, que são identificados pela doutrina como direitos de **terceira dimensão** ou **geração**. [20](#)

No Brasil, conforme já apontado, essa perspectiva está consagrada no texto de 1988, embora esboçada nos textos de 1946 e 1967 (e EC n. 1/69).

■ 1.2.2.7. *Constitucionalismo do futuro: o que podemos esperar?*

O **constitucionalismo do futuro** sem dúvida terá de consolidar os chamados *direitos humanos de terceira dimensão*, incorporando à ideia de constitucionalismo **social** os valores do constitucionalismo **fraternal** [21](#) e de **solidariedade**, avançando e estabelecendo um equilíbrio entre o constitucionalismo moderno e alguns excessos do contemporâneo.

Por isso, como bem anota **José Roberto Dromi**, o futuro do constitucionalismo “deve estar influenciado até identificar-se com a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a universalidade”.

Trata-se da Constituição do “**por vir**”, com os seguintes valores: [22](#)

■ **verdade:** a Constituição não pode mais gerar falsas expectativas; o constituinte só poderá “prometer” o que for viável cumprir, devendo ser transparente e ético;

■ **solidariedade:** trata-se de nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade dos povos, na dignidade da pessoa humana e na justiça social;

■ **consenso:** a Constituição do futuro deverá ser fruto de consenso democrático;

■ **continuidade:** ao se reformar a Constituição, a ruptura não pode deixar de levar em conta os avanços já conquistados;

■ **participação:** refere-se à efetiva participação dos “corpos

intermediários da sociedade”, consagrando-se a noção de democracia participativa e de Estado de Direito Democrático;

■ **integração:** trata-se da previsão de órgãos supranacionais para a implementação de uma integração espiritual, moral, ética e institucional entre os povos;

■ **universalização:** refere-se à consagração dos direitos fundamentais internacionais nas Constituições futuras, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana de maneira universal e afastando, assim, qualquer forma de desumanização.

■ 1.2.3. Esquematização do constitucionalismo

MOMENTO HISTÓRICO	DOCUMENTOS/ CARACTERÍSTICAS MARCANTES
ANTIGUIDADE	■ “Lei do Senhor” — hebreus — limites bíblicos ■ democracia direta — Cidades-Estados gregas
IDADE MÉDIA	■ Magna Carta de 1215
IDADE MODERNA	■ pactos e forais ou cartas de franquia ■ Petition of Rights de 1628 ■ Habeas Corpus Act de 1679 ■ Bill of Rights de 1689 ■ Act of Settlement de 1701
	■ contratos de colonização

CONSTITUCIONALISMO NORTE-AMERICANO	■ Compact (1620) ■ Fundamental Orders of Connecticut (1639) ■ Carta outorgada pelo rei Carlos II (1662) ■ Declaration of Rights do Estado de Virgínia (1776) ■ Constituição da Confederação dos Estados Americanos (1781)
CONSTITUCIONALISMO MODERNO	■ Constituição norte-americana de 1787 ■ Constituição francesa de 1791
CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO	■ totalitarismo constitucional ■ dirigismo comunitário ■ constitucionalismo globalizado ■ direitos de segunda dimensão ■ direitos de terceira dimensão (fraternidade e solidariedade)
CONSTITUCIONALISMO DO FUTURO	■ consolidação dos direitos de terceira dimensão: fraternidade e solidariedade ■ segundo Dromi, a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a universalidade são perspectivas para o constitucionalismo do futuro

■ 1.3. NEOCONSTITUCIONALISMO [23](#)

■ 1.3.1. Aspectos iniciais

A doutrina passa a desenvolver, a partir do início do século XXI, uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, denominada **neoconstitucionalismo**, ou, segundo alguns, **constitucionalismo pós-moderno**, ou, ainda, **pós-positivismo**.²⁴

Visa-se, dentro dessa nova realidade, não mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais.

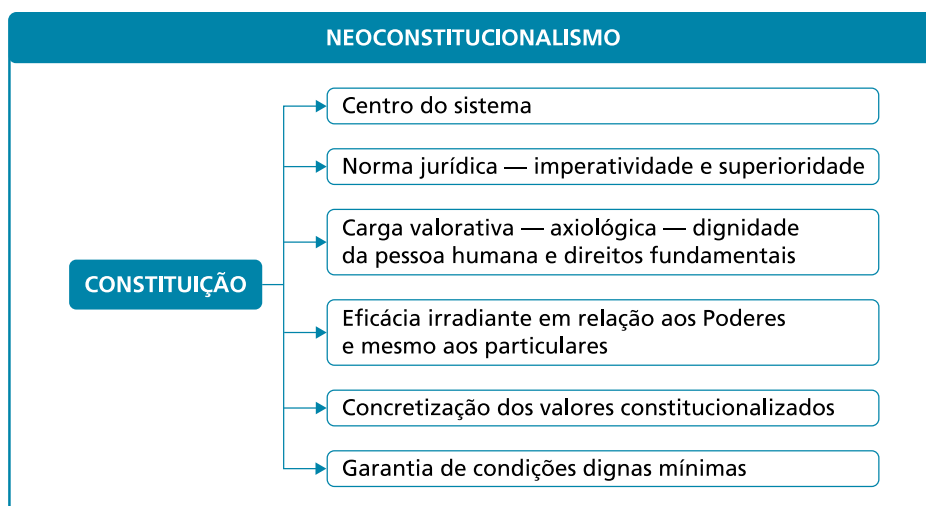
Kildare, de maneira interessante, anota que a perspectiva é de que “ao **constitucionalismo social** seja incorporado o **constitucionalismo fraternal** e de **solidariedade**”,²⁵ valores já destacados por Dromi dentro de um contexto de constitucionalismo do futuro ou do “por vir” (cf. *item 1.2.2.7*).

Nas palavras de Walber de Moura Agra, “o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das **prestações materiais prometidas pela sociedade**, servindo como ferramenta para a implantação de um **Estado Democrático Social de Direito**. Ele pode ser considerado como um movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas principais características podem ser mencionadas: **a)** positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais; **b)** onipresença dos princípios e das regras; **c)** inovações hermenêuticas; **d)** densificação da força normativa do Estado; **e)** desenvolvimento da justiça distributiva”.²⁶

E continua: “o seu modelo normativo não é o descritivo ou deontológico, mas o **axiológico**. No constitucionalismo moderno a diferença entre normas constitucionais e infraconstitucionais era apenas de grau, no neoconstitucionalismo a diferença é também axiológica. A ‘**Constituição como valor em si**’. O caráter ideológico do constitucionalismo moderno era apenas o de limitar o poder, o caráter ideológico do neoconstitucionalismo é o de concretizar os direitos fundamentais”.²⁷

CONSTITUCIONALISMO MODERNO	NEOCONSTITUCIONALISMO
■ hierarquia entre as normas	■ hierarquia entre normas não apenas formal, mas também axiológica — valor
■ limitação do poder	■ concretização dos direitos fundamentais

■ 1.3.2. Pontos marcantes do neoconstitucionalismo



■ **Estado constitucional de direito:** supera-se a ideia de Estado Legislativo de Direito, passando a Constituição a ser o **centro** do sistema, marcada por uma intensa **carga valorativa**. A lei e, de modo geral, os Poderes Públicos, então, devem não só observar a forma prescrita na Constituição, mas, acima de tudo, estar em consonância com o seu **espírito**, o seu **caráter axiológico** e os seus **valores** destacados. A Constituição, assim, adquire, de vez, o caráter de **norma jurídica**, dotada de **imperatividade**, **superioridade** (dentro do sistema) e **centralidade**, vale dizer, tudo deve ser interpretado a partir da Constituição.

■ **Conteúdo axiológico da Constituição:** para Barcellos, do ponto de vista **material**, sobressai o seguinte elemento dentro da noção de constitucionalismo: “(i) a incorporação explícita de **valores** e **opções**

políticas nos textos constitucionais, sobretudo no que diz respeito à promoção da **dignidade humana** e dos **direitos fundamentais**".[28](#)

Como importante marca das Constituições contemporâneas, além de realçar seus **valores** (especialmente após a Segunda Guerra Mundial), associados, particularmente, à ideia da dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Barcellos identifica a previsão de **opções políticas gerais** (como a redução de desigualdades sociais — art. 3.º, III) e **específicas** (como a prestação, por parte do Estado, de serviços de educação — arts. 23, V, e 205).

Nesse contexto, a partir do momento que os valores são constitucionalizados, o grande desafio do neoconstitucionalismo passa a ser encontrar mecanismos para sua efetiva **concretização**.

■ **Concretização dos valores constitucionais e garantia de condições dignas mínimas:** de acordo com a lição de Barcellos, completando, do ponto de vista **material**, destaca-se um outro elemento na concepção de constitucionalismo: "(ii) a expansão de conflitos específicos e gerais entre as opções normativas e filosóficas existentes dentro do próprio sistema constitucional".[29](#)

Sem dúvida, os valores constitucionalizados poderão entrar em choque, seja de modo **específico** (por exemplo, a *liberdade de informação e de expressão* e a *intimidade, honra e vida privada*), seja de modo **geral**, no que, conforme afirma, diz respeito "ao próprio papel da Constituição".

Em uma visão **substancialista** (a Constituição deveria impor "um conjunto de decisões valorativas que se consideram essenciais e consensuais"), ou mesmo designada de **procedimentalismo** (a Constituição deve "garantir o funcionamento adequado do sistema de participação democrático, ficando a cargo da maioria, em cada momento histórico, a definição de seus valores e de suas próprias convicções materiais"), em relação a qualquer das posições que se filie, mesmo no "procedimentalismo" deverão ser resguardadas as **condições de dignidade e dos direitos dentro, ao menos, de patamares mínimos**.[30](#)

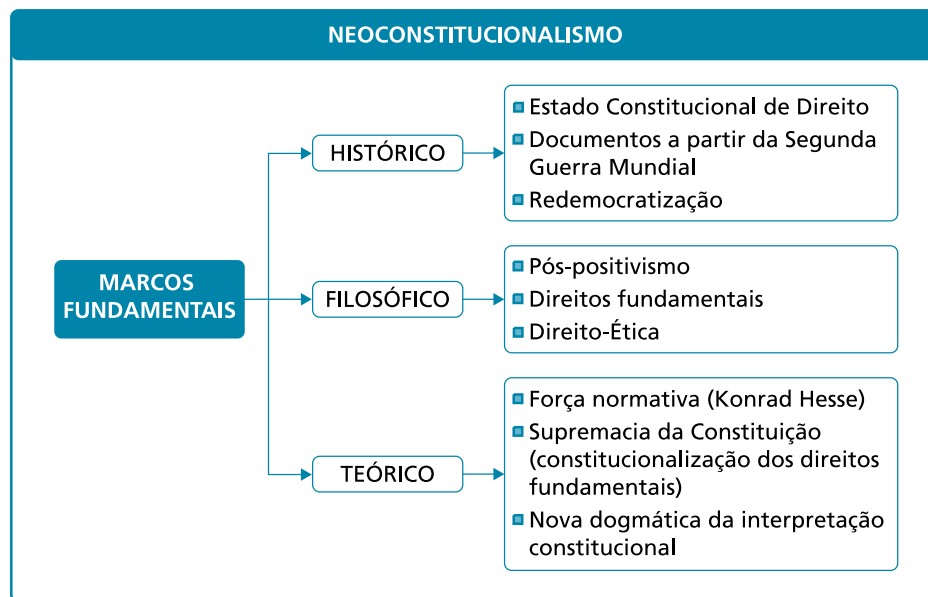
Ainda, segundo Dirley da Cunha Júnior, "... foi marcadamente decisivo para o delineamento desse novo Direito Constitucional, a reaproximação entre o **Direito** e a **Ética**, o **Direito** e a **Moral**, o **Direito** e a **Justiça** e demais **valores**

substantivos, a revelar a importância do homem e a sua ascendência a filtro axiológico de todo o sistema político e jurídico, com a consequente proteção dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana”.[31](#)

■ 1.3.3. Marcos fundamentais para se chegar a um “novo direito constitucional” (neoconstitucionalismo)

Em interessante trabalho, Barroso aponta três **marcos fundamentais** que definem a trajetória do direito constitucional para o atual estágio de “novo”: o **histórico**, o **filosófico** e o **teórico**.

Ao analisar o quadro a seguir, conclui-se que “o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como *marco histórico*, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como *marco filosófico*, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como *marco teórico*, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito”.[32](#)



Assim, podemos esquematizar: [33](#)

■ **histórico:** evidenciam-se aqui as Constituições do pós-guerra, na Europa, destacando-se a da Alemanha de 1949 (Lei Fundamental de Bonn) e o Tribunal Constitucional Federal (1951); a da Itália de 1947 e a instalação da Corte Constitucional (1956); a de Portugal (1976) e a da Espanha (1978), todas enfocando a perspectiva de **redemocratização** e **Estado Democrático de Direito**. No Brasil, o destaque recai sobre a Constituição de 1988, em importante processo democrático;

■ **filosófico:** o **pós-positivismo** aparece como o marco filosófico do neoconstitucionalismo.

A ideia de **jusnaturalismo moderno** se desenvolve a partir do século XVI, aproximando a **lei** da **razão** e se transformando, assim, na **filosofia natural do Direito**, e vai servir de sustentáculo, “fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos”, para as revoluções liberais, consagrando-se nas Constituições escritas e nas codificações. “Considerado metafísico e anticientífico, o direito natural foi empurrado para a margem da história pela ascensão do **positivismo jurídico**, no final do século XIX. Em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o Direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira metade do século XX. Sua decadência é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, regimes

que **promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade**. Ao fim da 2.^a Guerra, a ética e os valores começam a retornar ao Direito”.

Nesse contexto surge a noção do **pós-positivismo** como marco filosófico do **neoconstitucionalismo**. “O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto. Procura empreender uma **leitura moral do Direito**, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a **atribuição de normatividade aos princípios** e a **definição de suas relações com valores e regras**; a reabilitação da **razão prática** e da **argumentação jurídica**; a formação de uma **nova hermenêutica constitucional**; e o desenvolvimento de uma **teoria dos direitos fundamentais** edificada sobre o fundamento da **dignidade humana**. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o **Direito e a filosofia**”;

■ **teórico:** **a)** força normativa da Constituição; **b)** expansão da jurisdição constitucional; **c)** nova dogmática da interpretação constitucional.

Dentro da ideia de **força normativa** (Konrad Hesse), pode-se afirmar que a norma constitucional tem *status* de norma jurídica, sendo dotada de **imperatividade**, com as consequências de seu descumprimento (assim como acontece com as normas jurídicas), permitindo o seu cumprimento forçado.

No contexto de **expansão da jurisdição constitucional**, Barroso observa que, “antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de *supremacia do Poder Legislativo*, na linha da doutrina inglesa de soberania do Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade geral. A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não apenas novas constituições, mas também um **novo modelo**, inspirado pela experiência **americana**: o da **supremacia da Constituição**. A fórmula envolvia a **constitucionalização dos direitos fundamentais**, que ficavam imunizados em relação ao processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao Judiciário. Inúmeros países europeus vieram a adotar um modelo próprio de

controle de constitucionalidade, associado à criação de tribunais constitucionais”.

Ao confrontar **regras** (enunciados descritivos, aplicados de acordo com as regras de subsunção, isso quer dizer a aplicação e enquadramento do fato à norma) e **princípios** (normas que consagram valores), Barroso conclui no sentido de uma **nova dogmática da interpretação constitucional**, não mais restrita à denominada interpretação jurídica tradicional.

Assim, “... as especificidades das normas constitucionais (...) levaram a doutrina e a jurisprudência, já de muitos anos, a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de princípios aplicáveis à interpretação constitucional. Tais princípios, de natureza **instrumental**, e não material, são pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais. São eles, na ordenação que se afigura mais adequada para as circunstâncias brasileiras: o da **supremacia da Constituição**, o da **presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder público**, o da **interpretação conforme a Constituição**, o da **unidade**, o da **razoabilidade** e o da **efetividade**”.

Enfim, essas são as marcas do “novo direito constitucional” ou neoconstitucionalismo, que se evidencia ao propor a identificação de novas perspectivas, marcando, talvez, o início de um novo período do Direito Constitucional.

■ 1.4. O NOVO CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINO-AMERICANO. CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA (ANDINO OU INDÍGENA). ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL

O denominado **novo constitucionalismo latino-americano** (por alguns chamado de *constitucionalismo andino* ou *indígena*) culmina com a promulgação das Constituições do **Equador** (2008)³⁴ e da **Bolívia** (2009)³⁵ e sedimenta-se na ideia de **Estado plurinacional**,³⁶ reconhecendo, constitucionalmente, o direito à **diversidade cultural** e à **identidade** e, assim, revendo os conceitos de **legitimidade** e **participação popular**, especialmente de parcela da população historicamente excluída dos processos de decisão, como a população indígena.

Trata-se, inegavelmente, de necessária e real transformação estrutural e, assim, conforme aponta Grijalva, “o constitucionalismo plurinacional só pode ser **profundamente intercultural**, uma vez que a ele corresponde constituir-se no âmbito de relação igual e respeitosa de distintos povos e culturas, a fim de manter as diferenças legítimas, e eliminar — ou, ao menos, diminuir — as ilegítimas, mantendo a **unidade** como garantia da diversidade”.[37](#)

Esse modelo de **constitucionalismo pluralista** pressupõe rupturas paradigmáticas, muito bem delimitadas por Raquel Yrigoyen Fajardo, a saber: a) *colonialismo*, b) *constitucionalismo liberal*, c) *constitucionalismo social-integracionista* e d) *constitucionalismo pluralista* (delimitado por 3 ciclos de reformas constitucionais):[38](#)

■ **colonialismo:** vigorava a ideologia da “inferioridade natural dos índios”, em um modelo de subordinação;

■ **constitucionalismo liberal (século XIX):** construção do Estado-nação pelo “monismo jurídico”, ou seja, como bem anota Yrigoyen Fajardo, a existência de um único sistema jurídico dentro do Estado, sobressaindo-se um regramento geral para todos. A ideia de pluralismo jurídico, como forma de coexistência de vários sistemas normativos dentro de um mesmo espaço geopolítico... não era admitida pela ideologia do Estado-nação, havendo exclusão dos povos originários, dos afrodescendentes, das mulheres, das maiorias subordinadas, buscando a manutenção da sujeição dos índios.[39](#)

■ **constitucionalismo social-integracionista (século XX):** marcado pela Constituição do México de 1917 e a de Weimar (Alemanha) de 1919, há o reconhecimento de direitos sociais e sujeitos coletivos, com a ampliação das bases de cidadania. O Estado define o modelo de integração dos índios com o Estado e o mercado, não havendo, contudo, rompimento da ideia de Estado-nação e monismo jurídico.[40](#)

■ **constitucionalismo pluralista (séculos XX e XXI):** Yrigoyen Fajardo reconhece 3 ciclos marcantes e que ensejam importantes reformas constitucionais nos países latino-americanos, evidenciando-se novos atores sociais nos processos decisórios: a) *ciclo multicultural* (1982-1988); b)

ciclo pluricultural (1989-2005) e c) *ciclo plurinacional* (2006-2009).[41](#)
 Vejamos a esquematização:[42](#)

CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA			
	Ciclo Multicultural	Ciclo Pluricultural	Ciclo Plurinacional
CARACTERÍSTICAS	“introdução do direito — individual e coletivo — à identidade cultural, junto com a inclusão de direitos indígenas específicos”	“incorpora os direitos contidos no Convênio 169 da OIT. Este ciclo afirma o direito (individual e coletivo) à identidade e diversidade cultural, já introduzido no primeiro ciclo, mas desenvolve mais o conceito de ‘nação multiétnica’ e ‘estado pluricultural’, qualificando a natureza da população e avançando rumo ao caráter do Estado. Também reconhece o pluralismo jurídico, assim como novos direitos indígenas e de afrodescendentes”	“os povos indígenas demandam que sejam reconhecidos não apenas como ‘culturas diversas’, mas como nações originárias ou sujeitos políticos coletivos com direito a participar nos novos pactos do Estado, que se configurariam, assim, como Estados plurinacionais. E, além disso, reclamam, ao Estado, direitos sociais e um papel frente às transnacionais e poderes materiais tradicionais”
	Canadá	Colômbia — 1991	

PAÍSES	■ Canadá — 1982 ■ Guatemala — 1985 ■ Nicarágua — 1987 ■ Brasil — 1988	■ México — 1992 ■ Paraguai — 1992 ■ Peru — 1993 ■ Bolívia — 1994 ■ Argentina — 1994 ■ Equador — 1996/1998 ■ Venezuela — 1999	■ Equador — 2008 ■ Bolívia — 2009
DOCUMENTOS NORMATIVOS (INTERNACIONAIS)	■ Revisão da Convenção 107/OIT	■ Convenção 169/OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto n. 5.051/2004)	■ Aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas — 2007

■ 1.5. CONSTITUCIONALISMO E SOBERANIA POPULAR

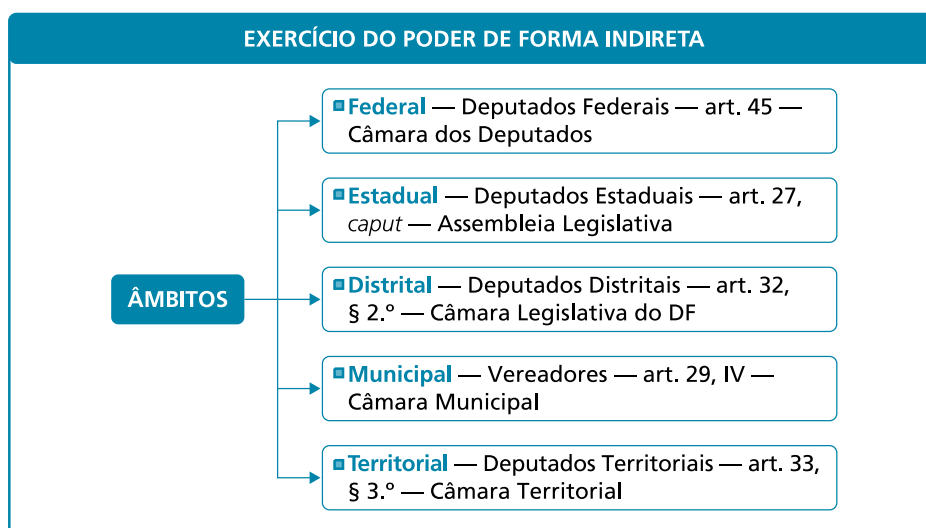
■ 1.5.1. Aspectos gerais

A ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição e de que esta deve conter **limitações ao poder autoritário** e regras de **prevalência dos direitos fundamentais** desenvolve-se no sentido da consagração de um **Estado Democrático de Direito** (art. 1.º, *caput*, da CF/88) e, portanto, de **soberania popular**.

Assim, de forma expressa, o parágrafo único do art. 1.º da CF/88 concretiza

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Vale dizer, mencionado artigo distingue **titularidade** de **exercício** do poder. O **titular** do poder é o **povo**. Como regra, o **exercício** desse poder, cujo titular, repita-se, é o povo, dá-se através dos **representantes do povo**, que, como veremos ao tratar do poder legislativo, são os Deputados Federais (âmbito federal), os Deputados Estaduais (âmbito estadual), os Deputados Distritais (âmbito do DF), os Vereadores (âmbito municipal) e os Deputados Territoriais (âmbito de eventuais Territórios Federais que venham a ser criados). Lembramos, desde já, que os Senadores da República Federativa do Brasil representam os Estados-Membros e o Distrito Federal, de acordo com o art. 46 da CF/88.



Além de desempenhar o poder de maneira indireta (democracia representativa), por intermédio de seus representantes, o povo também o realiza **diretamente** (democracia direta), concretizando a **soberania popular**, que, segundo o art. 1.º da Lei n. 9.709, de 18.11.1998 (que regulamentou o art. 14, I, II e III, da CF/88), “é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante: **plebiscito**, **referendo** e **iniciativa popular**”.

Podemos falar, então, que a CF/88 consagra a **democracia semidireta** ou **participativa**, verdadeiro **sistema híbrido** e que será mais bem desenvolvido no

participativa, verdadeiro **sistema híbrido** e que será mais bem desenvolvido no *capítulo 17*, ao qual remetemos o nosso querido leitor.

■ 1.6. QUESTÕES

1. De que forma a soberania popular se manifesta?

2. (TRF 3.^a Região — Juiz Federal/XI Concurso) A soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, por:

- a) plebiscito, referendo e iniciativa popular.
- b) plebiscito e iniciativa popular.
- c) plebiscito, referendo, iniciativa popular e comícios político-partidários.
- d) plebiscito e referendo.

3. (Procurador DF — 2004) O exercício do poder não pelo seu titular, mas por órgãos de soberania que atuam no interesse do povo constitui o sentido essencial do:

- a) princípio da dignidade da pessoa humana.
- b) princípio do sufrágio.
- c) princípio do pluralismo político.
- d) princípio da representação.
- e) princípio da soberania popular.

4. (DP/SP 2006 — FCC) O que assegura aos cidadãos o exercício dos seus direitos, a divisão dos poderes e, segundo um dos seus grandes teóricos, a limitação do governo pelo direito é:

- a) o constitucionalismo.
- b) a separação de poderes.
- c) o princípio da legalidade.
- d) o federalismo.
- e) o Estado Democrático de Direito.

5. (Procurador MP do TCE/MG — FCC/2007) No sentido de alcançar-se um ponto de equilíbrio entre as concepções extraídas do constitucionalismo moderno e os

Participação; III. Descontinuidade; IV. Integração; V. Normas programáticas; VI. Universalização; VII. Consenso.

Segundo Dromi, deverão marcar o constitucionalismo do futuro APENAS os valores indicados em:

- a) I, II, IV, VI e VII.
- b) I, II, III, VI e VII.
- c) I, IV, V, VI e VII.
- d) II, III, IV, V e VI.
- e) II, IV, V, VI e VII.

6. (MP/RN — CESPE/UnB/2009) Acerca do constitucionalismo, assinale a opção incorreta:

- a) A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma organização política fundada na limitação do poder absoluto.
- b) O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no direito constitucional, entre as quais se destaca a prevalência do positivismo jurídico, com a clara separação entre direito e valores substantivos, como ética, moral e justiça.
- c) O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantidores.
- d) O neoconstitucionalismo caracteriza-se pela mudança de paradigma, de Estado Legislativo de Direito para Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o sistema jurídico.
- e) As constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio da incorporação explícita, em seus textos, de anseios políticos, como a redução de desigualdades sociais, e de valores como a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais.

7. (Defensoria Pública — MP/FUMARC/2009) Constituiu-se no cerne do constitucionalismo social:

- a) O juiz, como boca da lei.
- b) Os interesses difusos.
- c) O voto censitário.
- d) O intervencionismo diversificado.

- d) O intervencionismo diversificado.
- e) Os direitos individuais.

8. (Atividades Notariais/Registro/TJ — MG — Vunesp/2009) Assinale a alternativa que contém uma afirmativa correta a respeito do constitucionalismo.

- a) O constitucionalismo teve seu marco inicial com a promulgação, em 1215, da Magna Carta inglesa.
- b) O constitucionalismo surge formalmente, em 1948, com a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
- c) A doutrina do Direito Constitucional é uníssona no entendimento de que o constitucionalismo surgiu com a revolução norte-americana resultando, em 1787, na Constituição dos Estados Unidos da América.
- d) É possível identificar traços do constitucionalismo mesmo na antiguidade clássica e na Idade Média.
- e) O constitucionalismo brasileiro inspirou-se fortemente no modelo constitucional do Estado da Inglaterra.

9. (MP/GO — 2010) 46. Segundo J. J. Gomes Canotilho, o constitucionalismo é uma “... teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo”. A partir dessa visão conceitual, assinale a alternativa incorreta:

- a) As constituições norte-americana, de 1787, e a francesa, de 1791, são os marcos históricos e formais do constitucionalismo moderno.
- b) O constitucionalismo garante aos cidadãos o exercício dos seus direitos, mesmo que tenha que limitar o poder do governo.
- c) A concepção de constituição dirigente é antagônica ao conceito de constitucionalismo.
- d) O neoconstitucionalismo busca ultrapassar a ideia de limitação do poder político para representar a busca de eficácia da Constituição, particularmente na efetivação dos direitos fundamentais.

10. (ANATEL — Analista Administrativo — Direito — CESPE/UnB/2006) O

limitar o poder e estabelecer um rol de direitos e garantias individuais, o que cria a necessidade de se instituir uma carta, em regra escrita, que possa juridicizar essa relação entre Estado e cidadão, de forma a se gerar mais segurança jurídica.

11. (PGE/PE — CESPE/UnB/2009) Tendo o texto abaixo como motivação, assinale a opção correta a respeito do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo:

Chega de ação. Queremos promessas. Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração: a velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a característica da nossa era.

Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus.

L. R. Barroso. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Internet: <jus2.uol.com.br> (com adaptações).

- a) O neoconstitucionalismo tem como marco filosófico o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais, no entanto, não permite uma aproximação entre direito e ética.
- b) A democracia, como vontade da maioria, é essencial na moderna teoria constitucional, de forma que as decisões judiciais devem ter o respaldo da maioria da população, sem o qual não possuem legitimidade.
- c) No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização de suas propostas fica condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador.

discrecionalidade do administrador.

- d) O constitucionalismo pode ser definido como uma teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representa uma técnica de limitação do poder com fins garantísticos.
- e) O neoconstitucionalismo não autoriza a participação ativa do magistrado na condução das políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

12. (TJ/CE — Titular de Serviços de Notas e de Registros — IESES/2011) Leia atentamente as proposições abaixo e assinale a que se apresentar correta:

- a) O poder constituinte inicial, por romper completamente com a ordem jurídica anterior, é ilimitado, absoluto e arbitrário.
- b) Acerca da história do constitucionalismo, é correto afirmar que Karl Loewenstein identificou indícios do seu surgimento entre os hebreus durante a Antiguidade, por ter lá encontrado certas limitações ao poder político, mormente aquelas que asseguravam aos profetas a legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos.
- c) A elaboração da Lei Orgânica, pelo Município, pode ser considerada verdadeira manifestação do poder constituinte decorrente, também conferido aos Estados-Membros da Federação.
- d) O sistema constitucional vigente criou a figura do poder constituinte derivado revisor, cuja manifestação, prevista no art. 3.º do ADCT, deve ocorrer a cada dez anos, visando manter atual o texto da Constituição.

13. (Delegado de Polícia — PC/GO — UEG/2013) O Constitucionalismo contemporâneo apresenta movimentos teóricos importantes, dentre os quais destacam-se o Neoconstitucionalismo, cuja característica é a presença hegemônica dos princípios como critério de interpretação, como fator de onipresença da Constituição Federal, e o Novo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, fundado nas novas perspectivas trazidas pelas Constituições da América Latina. Esses movimentos distinguem-se entre si, pois:

- a) o Neoconstitucionalismo valoriza a dimensão jurídica da Constituição Federal, enquanto para o Novo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano a busca da legitimidade democrática se dá pela maior e mais efetiva participação popular.

princípios do estado moderno, servindo-se dos modelos de freios e contrapesos, enquanto o Neoconstitucionalismo nega tal modelo.

- c) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano reconhece o pluralismo jurídico pautado na jurisdição estatal única, enquanto o Neoconstitucionalismo funda-se em uma jurisdição constitucional separada.
- d) o Neoconstitucionalismo inaugura um modelo de valorização da diversidade e do plurinacionalismo, enquanto o Novo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano assume e garante a associação da ideia Estado-nação.

14. (Rioprevidência — Especialista em Previdência Social — Gestão de Tecnologia da Informação — CEPERJ/2014) A expressão constitucionalismo, como apontam os juristas, é de origem recente e traduz o resultado dos movimentos contrários a determinados modelos de governo que foram predominantes em denominada quadra histórica. Nessa trilha, o constitucionalismo traduz:

- a) centralização de governo
- b) limitação do poder
- c) vitória do proletariado
- d) democracia socialista
- e) governo das elites

15. (Procurador do Estado/PE — CESPE/UnB/2009) Chega de ação. Queremos promessas. Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração: a velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a característica da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se

modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus (L. R. Barroso. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Internet: com adaptações). Tendo o texto acima como motivação, assinale a opção correta a respeito do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo:

- a) O neoconstitucionalismo tem como marco filosófico o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais, no entanto, não permite uma aproximação entre direito e ética.
- b) A democracia, como vontade da maioria, é essencial na moderna teoria constitucional, de forma que as decisões judiciais devem ter o respaldo da maioria da população, sem o qual não possuem legitimidade.
- c) No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização de suas propostas fica condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador.
- d) O constitucionalismo pode ser definido como uma teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representa uma técnica de limitação do poder com fins garantísticos.
- e) O neoconstitucionalismo não autoriza a participação ativa do magistrado na condução das políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

■ GABARITO ■

1. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da Lei n. 9.709, de 18.11.1998, e das normas constitucionais pertinentes, mediante: plebiscito, referendo e iniciativa popular.

2. “a”. Art. 14, I, II e III, da CF/88.

4. “a”.
5. “a”. “III. Descontinuidade” — está errado, pois o valor sugerido por Dromi é justamente o contrário, qual seja, a continuidade, a ideia de manter nos textos futuros os avanços; “V. Normas programáticas” — não reflete o sentido proposto por Dromi, já que violaria a verdade. Como se verificou na parte teórica, a Constituição não pode gerar falsas expectativas. Assim, a Constituição do “por vir” (futuro) deve estabelecer normas possíveis e eficazes, deixando de lado as normas que prometem situações inalcançáveis.
6. “b”. <i>Vide</i> parte teórica.
7. “d”.
8. “d”. <i>Vide</i> parte teórica.
9. “c”. <i>Vide</i> parte teórica.
10. “certa”. <i>Vide</i> parte teórica.
11. “d”.
12. “b”, conforme a parte teórica, <i>item 1.2.2.1</i> . A letra “a” está errada, pois, como estudaremos no <i>capítulo 4</i> , não se pode falar que o poder constituinte originário seja absoluto e arbitrário, apesar de ilimitado juridicamente. A letra “c” está errada consoante explicaremos no <i>item 4.5.3.2</i> . A letra “d” está errada, pois o poder de revisão se manifestaria a partir de 5 anos da promulgação do texto e uma única vez, estando, assim, o art. 3.º do ADCT, na medida em que já se manifestou, com a sua eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada (cf. <i>item 4.5.4</i>).
13. “a”.
14. “b”.
15. “d”. <i>Vide</i> parte teórica.

CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, CLASSIFICAÇÕES, ELEMENTOS E HISTÓRICO

Nesta parte devemos conceituar e classificar *Constituição*. Lembramos que ao conceituar ou classificar qualquer instituto surgirão diversos critérios, não sendo um mais certo que outro, talvez, no máximo, mais adequado. Procuramos trazer os que mais aparecem nos concursos públicos, dado o objetivo deste trabalho.

■ 2.1. CONCEITO

Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para definir o termo “Constituição”. Alguns autores preferem a ideia da expressão tipologia dos conceitos de Constituição em várias acepções. Vejamo-las.

■ 2.1.1. Sentido sociológico

Valendo-se do **sentido sociológico**, **Ferdinand Lassale**, em seu livro *¿Qué es una Constitución?*, defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma

simples “*folha de papel*”. A Constituição, segundo a conceituação de Lassale, seria, então, a *somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade*.

■ 2.1.2. Sentido político

Na lição de **Carl Schmitt**, encontramos o **sentido político**, que distingue *Constituição de lei constitucional*. Constituição, conforme pondera José Afonso da Silva ao apresentar o pensamento de Schmitt, “... só se refere à decisão política fundamental (estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática etc.); as leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional, mas não contêm matéria de decisão política fundamental”.¹

Pode-se afirmar, portanto, em complemento, que, na visão de Carl Schmitt, em razão de ser a Constituição produto de certa **decisão política**, ela seria, nesse sentido, a **decisão política do titular do poder constituinte**.

■ 2.1.3. Sentido material e formal

Constituição também pode ser definida tomando-se o *sentido material e formal*, critério esse que se aproxima da classificação proposta por Schmitt.

Do ponto de vista *material*, o que vai importar para definirmos se uma norma tem caráter constitucional ou não será o seu *conteúdo*, pouco importando a forma pela qual foi essa norma introduzida no ordenamento jurídico. Constitucional será, então, aquela norma que defina e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais (formas de Estado, governo, seus órgãos etc.). Trata-se do que Schmitt chamou de *Constituição*.

Por outro lado, quando nos valemos do critério *formal*, que, de certa maneira, também englobaria o que Schmitt chamou de “lei constitucional”, não mais nos interessará o conteúdo da norma, mas sim a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Nesse sentido, as normas constitucionais serão aquelas introduzidas pelo poder soberano, por meio de um processo legislativo mais

difícultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação das demais normas do ordenamento.

Valendo-nos das definições acima, fazemos duas observações:

a) em primeiro lugar, por mais que pareça estranho dizer, ao eleger o **critério material**, torna-se possível encontrarmos normas constitucionais *fora do texto constitucional*, na medida em que o que interessa no aludido conceito é o conteúdo da norma, e não a maneira pela qual ela foi introduzida no ordenamento interno. Como o próprio nome sugere e induz, o que é relevante no critério material é a **matéria**, pouco importando sua forma;

b) em segundo lugar, em se tratando do **sentido formal**, qualquer norma que tenha sido introduzida por meio de um procedimento mais difícil (do que o procedimento de elaboração das normas infraconstitucionais), por um poder soberano, terá natureza constitucional, não importando o seu conteúdo (vale dizer, tomando-se o sentido formal, o que nos interessa é a **forma** de nascimento da norma). Lembramos um exemplo que supomos ilustrar bem o raciocínio: trata-se do art. 242, § 2.º, da CF/88, que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.

Pois bem, essa situação definida no citado art. 242, § 2.º, da CF/88, do ponto de vista **material**, de modo algum traz elementos que, por sua essência, sejam constitucionais, traduzindo regras estruturais e fundamentais da sociedade. No entanto, do ponto de vista **formal**, essa norma será tão constitucional como, por exemplo, o artigo que garante o princípio da igualdade. Isso porque o que nos interessa nesse sentido classificatório não é o conteúdo da norma, mas sim a maneira pela qual foi introduzida no ordenamento interno. Ela é tão constitucional como qualquer norma introduzida pelo poder constituinte originário (e pelo derivado, desde que observadas as regras definidas pelo originário),² devendo todo ato normativo respeitá-la, sob pena de padecer do vício de inconstitucionalidade.

Verifica-se uma forte tendência no direito brasileiro a se adotar um critério

misto em razão do art. 5.º, § 3.º, que admite que tratados internacionais de direitos humanos (matéria) sejam incorporados como emendas, desde que obedeçam a uma forma, ou seja, a um processo diferenciado de incorporação.

■ 2.1.4. Sentido jurídico

Hans Kelsen é o representante desse sentido conceitual, alocando a Constituição no mundo do **dever-ser**, e não no mundo do **ser**, caracterizando-a como fruto da **vontade racional** do homem, e não das leis naturais.

José Afonso da Silva, traduzindo o pensamento de Kelsen, conclui que “... constituição é, então, considerada *norma* pura, puro *dever-ser*, sem qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos: no *lógico-jurídico* e no *jurídico-positivo*. De acordo com o primeiro, *Constituição* significa *norma fundamental hipotética*, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição *jurídico-positiva*, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau”.³

Também assim o entendimento de Michel Temer, ao tratar da teoria kelseniana, observando que o jurista de Viena descreve a existência de dois planos distintos no direito, conforme acima salientado por José Afonso da Silva: “o jurídico-positivo e o lógico-jurídico. Aquele corporificado pelas normas postas, positivadas. O outro (lógico-jurídico) situa-se em nível do suposto, do hipotético. Umas são normas postas; outra é suposta”.⁴

No direito percebe-se um verdadeiro **escalonamento de normas**, uma constituindo o fundamento de validade de outra, numa **verticalidade hierárquica**. Uma norma, de hierarquia inferior, busca o seu fundamento de validade na norma superior e esta, na seguinte, até chegar à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional.

A Constituição, por seu turno, tem o seu fundamento de validade na **norma hipotética fundamental**, situada no **plano lógico**, e não no jurídico,

caracterizando-se como fundamento de validade de todo o sistema, determinando a obediência a tudo o que for posto pelo Poder Constituinte Originário.

Para facilitar a fixação da matéria, destacamos a teoria de Kelsen no quadro a seguir:

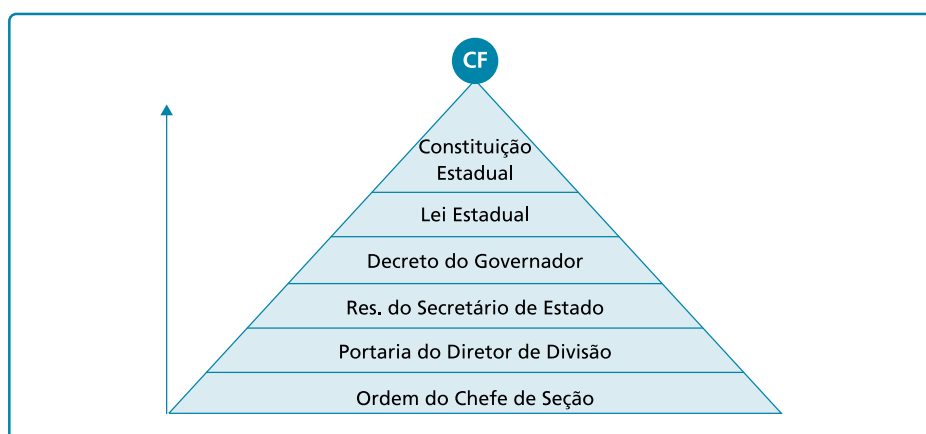
PLANO LÓGICO-JURÍDICO
■ norma fundamental hipotética ■ plano do suposto ■ fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva
PLANO JURÍDICO-POSITIVO
■ norma posta, positivada ■ norma positivada suprema

Esclarecedoras são as palavras de Michel Temer sobre a **verticalidade hierárquica** descrita, citando, como exemplo, o indeferimento, pelo chefe de seção de uma repartição pública, de um requerimento formulado. Trata-se de verdadeiro comando individual, que deverá estar em consonância com as normas superiores, ou seja: “... devo compatibilizar aquela ordem com a Portaria do Diretor de Divisão; esta com a Resolução do Secretário de Estado; a Resolução com o Decreto do Governador; este com a Lei Estadual; a Lei Estadual com a Constituição do Estado (se se tratar de Federação); esta com a Constituição Nacional. Tudo para verificar se os comandos expedidos pelas várias autoridades, sejam executivas ou legislativas, encontram verticalmente suporte de validade”.⁵

E, por fim, como visto, a Constituição Nacional encontrará o seu fundamento

de validade na **norma hipotética fundamental**, esta, o fundamento de validade de todo o sistema. Trata-se de **norma suposta**, e não posta, uma vez que **não editada por nenhum ato de autoridade**. Figura, como referimos, no plano **lógico-jurídico**, prescrevendo a observância do estabelecido na Constituição e nas demais normas jurídicas do sistema, estas últimas fundamentadas na própria Constituição. A norma fundamental, hipoteticamente suposta, prescreve a observância da primeira Constituição histórica. [6](#)

Daí, partindo da exemplificação proposta por Michel Temer, estabelecemos, graficamente, a ideia da “pirâmide” de Kelsen, consagrando a verticalidade hierárquica das normas e a Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema e, assim, o princípio da supremacia da Constituição:



■ 2.1.5. Sentido culturalista

Nesse sentido, pode-se dizer que a Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela sociedade e que nela pode influir. Ou, como destacou J. H. Meirelles Teixeira, trata-se de “... uma *formação objetiva de cultura* que encerra, ao mesmo tempo, elementos históricos, sociais e racionais, aí intervindo, portanto, não apenas fatores *reais* (natureza humana, necessidades individuais e sociais concretas, raça, geografia, uso, costumes, tradições, economia, técnicas), mas também *espirituais* (sentimentos, ideias morais, políticas e religiosas, valores), ou ainda elementos puramente *racionais* (técnicas jurídicas, formas políticas, instituições, formas e conceitos jurídicos *a priori*), e

finalmente elementos *voluntaristas*, pois não é possível negar-se o papel de vontade humana, da livre adesão, da vontade política das comunidades sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e social, e de organização do Direito e do Estado”.⁷

Em seguida, conclui o ilustre professor que a concepção culturalista do direito conduz ao conceito de uma **Constituição Total** em uma visão suprema e sintética que “... apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos *econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos*, a fim de abranger o seu conceito em uma *perspectiva unitária*”. Desse modo, sob o conceito culturalista de Constituição, “... as Constituições positivas são *um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela Cultura total, e ao mesmo tempo condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político*”.⁸

■ 2.1.6. Constituição aberta

Grande parte dos publicistas vem anunciando a ideia de uma Constituição aberta, no sentido de que ela possa permanecer dentro de seu tempo e, assim, evitar o risco de desmoronamento de sua “força normativa”.

Para Canotilho, dentro da perspectiva de uma **Constituição aberta**, “relativiza-se a *função material de tarefa* da Constituição e justifica-se a ‘desconstitucionalização’ de elementos substantivadores da ordem constitucional (Constituição econômica, Constituição do trabalho, Constituição social, Constituição cultural). A historicidade do direito constitucional e a indesejabilidade do ‘perfeccionismo constitucional’ (a Constituição como estatuto detalhado e sem aberturas) não são, porém, incompatíveis com o caráter de *tarefa e projecto* da lei constitucional. Esta terá de ordenar o processo da vida política fixando limites às tarefas do Estado e recortando dimensões prospectivas traduzidas na formulação dos fins sociais mais significativos e na identificação de alguns programas da conformação constitucional”.⁹

■ 2.1.7. Concepções da Constituição: qual o seu papel no ordenamento jurídico de um país?

Virgílio Afonso da Silva, depois de fazer **críticas** às classificações (da Constituição) apresentadas pela doutrina brasileira (**tipologia**), muitas vezes, em sua opinião, sem utilidade prática ou teórica limitada, propõe a análise do **papel da Constituição**, ou, ainda, da sua **função no ordenamento jurídico** e a sua **relação com a atividade legislativa ordinária**, analisando a **capacidade de conformação** atribuída ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada. [10](#)

Dentro dessa perspectiva de análise do papel da Constituição ou da sua função, destacamos, também, a concepção proposta no trabalho de Gustavo Zagrebelsky (*Il diritto mite*). Passamos, então, a analisar essas quatro propostas:

- **Constituição-lei.**
- **Constituição-fundamento (Constituição-total).**
- **Constituição-moldura.**
- **Constituição dúctil (Constituição maleável, *costituzione mite*).**

■ 2.1.7.1. **Constituição-lei**

Para o autor, muito embora não mais viável na maioria das democracias constitucionais contemporâneas, a **Constituição-lei** em muito **pouco se distingue da legislação ordinária**. “Talvez a principal defesa desse tipo de Constituição seja aquela formulada por Gerhard Anschütz em fins do século XIX. Segundo ele, **a Constituição ‘não está acima do poder legislativo, mas à disposição dele’**. Nesse sentido, a Constituição é, na verdade, *uma lei como qualquer outra*. Os dispositivos constitucionais, especialmente os direitos fundamentais, teriam uma função meramente indicativa, pois apenas indicariam ao legislador um possível caminho, que ele não precisaria necessariamente seguir.” [11](#) Esse modelo, certamente, permite a **justificação** da tese acerca da **supremacia do parlamento**, mitigada, contudo, em tempos mais recentes, como pode ser observado, para se ter um exemplo, na Inglaterra a partir da

entrada em vigor do *Human Rights Act* (cf. item 2.4.2).

■ 2.1.7.2. **Constituição-fundamento (Constituição-total)**

Por sua vez, na **Constituição-fundamento (Constituição-total)**, a onipresença (**ubiquidade**) da Constituição é tamanha que a área reservada ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada se torna muito pequena. Assim, esses atos passam a ser encarados como instrumentos da realização da Constituição.

Conforme anota Virgílio Afonso da Silva, “a ideia central desse conceito consiste na reivindicação de que a Constituição é a lei fundamental, não somente de toda a atividade estatal e das atividades relacionadas ao Estado, mas também a **lei fundamental de toda a vida social**. Um dos exemplos mais marcantes nesse sentido é a teoria da constituição aberta, de Peter Häberle, que, embora não sustente um conceito de Constituição-total, defende uma concepção de interpretação constitucional que, por expandir de tal forma a abrangência da Constituição, acaba refletindo uma ideia de Constituição-total. Segundo Häberle, todo aquele que vive o que é regulado pela norma constitucional é também um intérprete dela. Isso significa que praticamente todas as ações humanas seriam ao mesmo tempo reguladas pela Constituição e uma manifestação de uma interpretação constitucional, o que teria como consequência o fato de que nenhuma área da vida teria independência das normas constitucionais. O legislador, nesse sentido, seria um mero intérprete da Constituição, e sua tarefa consistiria sobretudo na efetivação dos direitos fundamentais. Não é difícil notar que, para os outros ramos do direito, essa concepção de Constituição deixa pouco ou nenhum espaço livre. Na pena irônica de Forsthoff, tudo seria definido pela Constituição, até mesmo a produção de termômetros para a febre”.¹²

Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva identifica uma inegável **aproximação** entre a **Constituição dirigente** e esse descrito sentido de **Constituição-fundamento** ou **total**, já que a Constituição dirigente apresenta uma ideia subjacente, qual seja, a de **“fixar um plano de ação para a transformação da**

sociedade”.¹³

Ao final, o autor apresenta uma severa e pouco reconhecida realidade que impera na jurisdição constitucional brasileira e na doutrina pátria. Muitas vezes, inegavelmente, esse sentido profundo de onipresença se verifica na interpretação da amplitude de normas ditas de reprodução obrigatória da Constituição Federal nas Constituições Estaduais (não dando abertura para o constituinte derivado), ou mesmo ao se afirmar que o ato normativo extrapola os limites da Constituição, destacando-se, como exemplo, a posição da doutrina que entende inconstitucional a exigência de preenchimento de certos requisitos para o ingresso em juízo com a ação de *habeas data* (entendimento esse, aliás, já superado pelo STF — cf. *item 14.11.6.3*).

Como observa, “as normas constitucionais, nesse sentido, não somente irradiarão efeitos pelos outros ramos do direito: **elas determinarão o conteúdo deles por completo**”.¹⁴

■ 2.1.7.3. *Constituição-moldura*

A **Constituição-moldura** (que Canotilho prefere chamar de **Constituição-quadro**) seria uma **proposta intermediária** entre os dois conceitos trazidos *supra*, evitando-se a politização excessiva da *Constituição-lei* (já que a sua concretização fica destinada ao legislador, estando ao seu serviço), ou a judicialização excessiva, decorrente do sentido de *Constituição-total* (já que ao legislador não sobraria qualquer espaço de atuação, sobrecarregando o Judiciário para verificar se houve ou não abuso).

Como bem observa Virgílio Afonso da Silva, “a metáfora da moldura, no campo da teoria constitucional, é usada para designar uma Constituição que apenas sirva de limites para a atividade legislativa. Ela é apenas uma moldura, sem tela, sem preenchimento. À jurisdição constitucional cabe apenas a tarefa de controlar se o legislador age dentro da moldura. *Como* o legislador age no interior desses limites é uma questão de oportunidade política. Segundo Starck, entender a Constituição como moldura significa sustentar que nem tudo está

predefinido pela Constituição e que inúmeras questões substanciais estão sujeitas à simples decisão da maioria parlamentar no processo legislativo ordinário. Definir a ‘largura’ da moldura, que funcionará como simples limitação ao poder estatal, é a tarefa da interpretação constitucional. Mas essa seria sua única tarefa. Todo o resto é questão de oportunidade política”. [15](#)

■ 2.1.7.4. **Constituição dúctil (Constituição maleável, suave)** **(“Costituzione mite” — Gustavo Zagrebelsky)**

Conforme observa Canotilho, entre as novas avançadas sugestões da moderna teoria da Constituição está a denominada por Zagrebelsky **Constituição dúctil** ou **maleável, suave** (*Costituzione mite*), “para exprimir a necessidade de a Constituição acompanhar a perda do centro ordenador do estado e **refletir o pluralismo social, político e econômico**. Neste sentido, a uma Constituição caberá a tarefa básica de assegurar apenas as condições possibilitadoras de uma vida em comum, mas já não lhe pertence realizar diretamente um projeto predeterminado dessa vida comunitária. As Constituições concebem-se, pois, como **plataformas de partida** para a realização de políticas constitucionais diferenciadas que utilizem em termos inventivos os ‘vários materiais de construção’ semeados nos textos constitucionais”. [16](#)

Assim, a sobrevivência de atual **sociedade complexa, pluralista e democrática** depende, reconhecendo-se a importância de uma dogmática “fluida”, da identificação de um modelo de *Constituição dúctil (maleável)* a assegurar, dentro dos seus limites e de uma perspectiva de **coexistência**, a espontaneidade da vida social e, assim, as condições para a vida em comum. [17](#)

■ 2.2. CROWDSOURCED CONSTITUTION: O LEGADO DA EXPERIÊNCIA PIONEIRA DA ISLÂNDIA (2011) [18](#)

Com a sua independência da Dinamarca em 1944, a **Islândia**, por referendo nacional, adotou documento provisório como a sua nova Constituição

republicana, estabelecendo as perspectivas de sua necessária revisão. Por falta de consenso político, contudo, o processo revisional não foi implementado.

Em 2008, a Islândia enfrentou grave **crise financeira**, surgindo, então, movimentos para uma imediata revisão constitucional, destacando-se a denominada, na língua inglesa, *Kitchenware Revolution* (algo como “Panelaço”), e que sinalizavam o total descontentamento da população com as autoridades que levaram o país ao **colapso econômico**.

Em 14 de novembro de 2009, um grupo de cerca de 1.200 participantes, mas sem reconhecimento oficial, realizou conferência na capital do país (*Reykjavík*, que, em português, pode ser traduzido como Reiquejavique ou Reiquiavique), intitulando-se Assembleia Nacional (*Thjodfundur*), comprovando a falta de aceitação popular dos governantes, bem como a real necessidade de uma nova Constituição.

Em 27 de novembro de 2010, houve a eleição pelo povo de 25 indivíduos para, em assembleia nacional constituinte, sem vinculação partidária, estabelecer a nova Constituição. Em razão de apontados problemas técnicos com o processo de escolha dos representantes, a Suprema Corte da Islândia invalidou as escolhas.

Os nomes, contudo, foram reconhecidos como legítimos e, assim, estabeleceu-se um “Conselho Constitucional” para a elaboração de um esboço (projeto, rascunho) de Constituição (*draft*).

As discussões foram transmitidas ao vivo e com a possibilidade de participação popular por meio das **redes sociais**, como o Twitter, Facebook, Youtube e Flickr. Mais de 3.600 sugestões foram postadas na página oficial no Facebook. Em 29 de julho de 2011, o documento (*draft*) foi encaminhado ao Parlamento.

Antes da deliberação parlamentar, havia a previsão de análise do documento por **referendo popular**, sem caráter vinculativo e que foi realizado em 20 de outubro de 2012, contando com a participação de 49% dos eleitores e, desses, 73% reconhecendo o *draft* como a nova Constituição do país.

Infelizmente, o Parlamento não aprovou o documento, seja por sua troca

durante o processo de elaboração do *draft* (perda de apoio político), seja pela presença, em sua composição, de uma ala extremamente conservadora.

A experiência islandesa, contudo, e apesar da particular realidade de ter mais de 95% de sua pequena população de cerca de 320.000 habitantes conectada à internet (o maior percentual no mundo!), revela uma **nova forma de democracia** e de **participação popular** por meio das **redes sociais** (internet) e que, sem dúvida, passa a servir de **modelo para o futuro**.

Estamos diante daquilo que vem sendo denominado ***crowdsourced constitution*** e que se implementa pela participação popular por meio da internet (*crowdsourcing*), em um **processo constituinte** bastante interessante de “**terceirização para a multidão**”.¹⁹ Sem dúvida, as **novas formas de democracia** utilizando as **ferramentas da tecnologia** podem ajudar nesse modelo de verdadeira **Constituição colaborativa**.

Dentro dessa perspectiva, influenciado pela experiência da Islândia, destacamos movimento similar que vem sendo percebido na **Inglaterra** no sentido de se elaborar ou não uma Constituição escrita. O debate acontece depois de **800 anos** do aniversário da **Magna Carta de 1215** e tem estimulado a participação popular por meio das redes sociais (*crowdsourcing*), estando fixada data no mês de junho de 2015 (aniversário da Magna Carta) para a apresentação do documento final (*draft*).²⁰

No **Brasil**, com o lema “**participação virtual, cidadania real**”, lançado em 2009, destacamos o portal “**E-democracia**” da **Câmara dos Deputados** (<<http://edemocracia.camara.gov.br>>), cuja proposta é, “por meio da internet, incentivar a participação da sociedade no debate de temas importantes para o país”. E, conforme sustentado, “o envolvimento dos cidadãos na discussão de novas propostas de lei contribui para a formulação de políticas públicas mais realistas e implantáveis”.

O portal está dividido em dois grandes espaços de participação: “as **Comunidades Legislativas** e o **Espaço Livre**. No *primeiro*, você pode participar de debates de temas específicos, normalmente, relacionados a projetos de lei já existentes. Essas Comunidades oferecem diferentes instrumentos de

participação e, ainda, orientações quanto ao andamento da matéria no Congresso Nacional. Já no *Espaço Livre*, você mesmo pode definir o tema da discussão e ser o grande motivador dela. O debate será acompanhado pela equipe e-Democracia e pode vir a se tornar uma Comunidade Legislativa. Os parlamentares envolvidos com a matéria acompanham as discussões e as consideram para auxiliar suas decisões”.[21](#)

O **Senado Federal**, por sua vez, pelo **Ato da Mesa n. 3/2011**, instituiu o programa e o portal “**E-Cidadania**” “com o objetivo de estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos, por meio da tecnologia da informação e comunicação, nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação da Casa”, estando o portal estruturado nos seguintes componentes:

- **e-Legislação:** “espaço destinado ao debate e à proposição de novas leis e alteração da legislação vigente ou projetos em tramitação”;

- **e-Fiscalização:** “espaço destinado ao acompanhamento do orçamento brasileiro e das ações administrativas do Senado Federal”;

- **e-Representação:** “espaço destinado à expressão da opinião e manifestações do cidadão sobre temas de interesse da sociedade e projetos em tramitação”.[22](#)

As experiências ainda se mostram muito tímidas e, infelizmente, pouco divulgadas, apesar das diversas “contas” nas redes sociais.[23](#) Consideramos as propostas bastante interessantes e esperamos, no futuro, que essa importante instrumentação de **participação popular** possa ser utilizada como instrumento balizador e indispensável para a tomada de decisões políticas.

■ 2.3. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA[24](#)

■ 2.3.1. Aspectos iniciais

A introdução da ideia de “**constitucionalização simbólica**” deve-se a

Marcelo Neves em trabalho apresentado para a obtenção do cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco realizado em 1992.

Uma primeira versão foi publicada pela Editora Acadêmica, sendo, em seguida, o texto editado em alemão, quando sofreu ampla revisão.

Depois, referido trabalho foi trazido do alemão para o português, com acréscimo de alguns textos e notas. Vejamos as suas principais considerações.²⁵

Marcelo Neves, na apresentação do trabalho, esclarece que o estudo pretende “... abordar o significado social e político de textos constitucionais, exatamente na relação inversa da sua concretização normativo-jurídica. Em outras palavras, a questão refere-se à **discrepância entre a função hipertroficamente simbólica e a insuficiente concretização jurídica de diplomas constitucionais**. O problema não se reduz, portanto, à discussão tradicional sobre ineficácia das normas constitucionais. Por um lado, pressupõe-se a distinção entre texto e norma constitucionais; por outro, procura-se analisar os efeitos sociais da legislação constitucional normativamente ineficaz. Nesse contexto, discute-se a função simbólica de textos constitucionais carentes de concretização normativo-jurídica”.²⁶

■ 2.3.2. Legislação simbólica

Em um primeiro momento, o autor busca desenvolver o conceito de **legislação simbólica** partindo da teoria do direito e da ciência política alemã das duas últimas décadas do século XX.

Analizando o trabalho de diversos autores (Cassirer, Lévi-Strauss, Bourdieu, Freud, Jung, Lacan, Castoriadis, Peirce, Firth, Saussure, Carnap, Luhmann e outros), Marcelo Neves apresenta uma delimitação semântica da expressão “legislação simbólica” (após ter determinado a ambiguidade entre “símbolo”, “simbólico” e “simbolismo”).

Nas suas palavras, a **legislação simbólica** “... aponta para o predomínio, ou mesmo **hipertrofia**, no que se refere ao sistema jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei, sobretudo em detrimento da função

jurídico-instrumental”.[27](#)

Com base em **Harald Kindermann**, Marcelo Neves propõe, então, um modelo tricotômico para a “tipologia da legislação simbólica”, estabelecendo que o seu conteúdo pode ser: “a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado e c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatatórios”.

■ 2.3.2.1. **Confirmação de valores sociais**

Nesse caso, o legislador assume uma posição em relação a determinados conflitos sociais e, ao consagrar certo posicionamento, para o grupo que tem a sua posição amparada na lei, essa “**vitória legislativa**” se caracteriza como verdadeira superioridade da concepção valorativa, **sendo secundária a eficácia normativa da lei**. Assim, o grupo prestigiado procura influenciar a atividade legiferante, fazendo prevalecer os seus valores contra os do grupo “adversário”.

Neves traz como exemplo clássico a **lei seca** nos Estados Unidos. Conforme destaca ao lembrar Gusfield, “a sua tese central afirma que os defensores da proibição de consumo de bebidas alcoólicas não estavam interessados na sua eficácia instrumental, mas sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindo-se a respectiva legislação como símbolo de *status*. Nos conflitos entre protestantes/nativos defensores da lei proibitiva e católicos imigrantes contrários à proibição, a ‘vitória legislativa’ teria funcionado simbolicamente a um só tempo como ‘ato de deferência para os vitoriosos e de degradação para os perdedores’, sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais”.[28](#)

Cita, ainda, a legislação sobre o **aborto** na Alemanha e sobre os **estrangeiros** na Europa. A confirmação de um dos valores antagônicos teria um papel muito mais simbólico que efetivo. A “legislação simbólica destinada primariamente à confirmação de valores sociais tem sido tratada basicamente como meio de diferenciar grupos e os respectivos valores ou interesses. Constituiria um caso de política simbólica por ‘gestos de diferenciação’, os quais ‘apontam para a glorificação ou degradação de um grupo em oposição a outros dentro da

sociedade””.[29](#)

■ 2.3.2.2. *Demonstração da capacidade de ação do Estado no tocante à solução dos problemas sociais (legislação-álibi)*

Além de ter o objetivo de confirmar valores de determinados grupos, a legislação simbólica pode ter o objetivo de assegurar **confiança** nos sistemas jurídico e político.

Diante de certa insatisfação da sociedade, a **legislação-álibi** aparece como uma resposta pronta e rápida do governo e do Estado.

Busca a legislação-álibi dar uma aparente solução para problemas da sociedade, mesmo que mascarando a realidade. Destina-se, como aponta Neves, “... a criar a imagem de um Estado que responde normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais não sejam realmente normatizadas de maneira consequente conforme o respectivo texto legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras alternativas, desempenhando uma função ‘ideológica’”.[30](#)

Enfim, a legislação-álibi tem o “poder” de introduzir um sentimento de “bem-estar” na sociedade, solucionando tensões e servindo à “lealdade das massas”.

Como exemplo, Neves lembra a **prestação de contas dos políticos** nos períodos eleitorais, sem se ter condições de assegurar que a lei criada cumpriu efetivamente o seu papel.

Lembra, ainda, após grave problema decorrente da venda de peixes causadores de doenças intestinais, na Alemanha, a divulgação de uma lei que procurou controlar a situação, sem sucesso, porém, dada a sua complexidade e a necessidade de outras medidas.

No Brasil, destaca **mudanças na legislação penal** como mera reação simbólica às pressões da sociedade buscando reduzir a criminalidade. Como exemplo temos a **Lei n. 11.923/2009**, que acrescenta parágrafo ao art. 158 do Código Penal, para tipificar o chamado **“sequestro relâmpago”**.

Neves faz, porém, um alerta sobre o uso exagerado da legislação simbólica e o risco de seu fracasso. “Isso porque o emprego abusivo da legislação-álibi leva à ‘descrença’ no próprio sistema jurídico, ‘transforma persistentemente a consciência jurídica’ (...); disso resulta que o público se sente enganado, os atores políticos tornam-se cínicos”.[31](#)

■ **2.3.2.3. Adiamento da solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios**

Ainda, conforme anota Neves, a **legislação simbólica** também pode “... servir para adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. Nesse caso, as divergências entre grupos políticos não são resolvidas por meio do ato legislativo, que, porém, será aprovado consensualmente pelas partes envolvidas, exatamente porque está presente a perspectiva da ineficácia da respectiva lei. O acordo não se funda então no conteúdo do diploma normativo, mas sim na transferência da solução do conflito para um futuro indeterminado”.[32](#)

Cita, como exemplos, a Constituição de Weimar e a lei norueguesa sobre empregados domésticos de 1948. Em relação a esta última, os empregados ficam satisfeitos, pois a lei aparentemente fortalece a proteção social. Por sua vez, os empregadores também se satisfazem, já que a lei, como apresentada, não tem perspectiva de efetivação, devido à sua “evidente impraticabilidade”.

Dessa forma, conclui, “... abrandando-se um conflito político interno através de uma ‘lei aparentemente progressista’, ‘que satisfazia ambos os partidos’, transferindo-se para um futuro indeterminado a solução do conflito social subjacente”.[33](#)

■ **2.3.2.4. Efeitos sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica**

Neves aponta que, além dessa visão simplista de inexistência ou irrelevância social da legislação simbólica, ela também apresenta **efeitos sociais latentes**,

que, em muitos casos, seriam mais relevantes que os “efeitos manifestos” que lhe faltam.

Exemplifica com uma lei tributária que, muito embora seja eficaz, pode trazer com ela recessão, inflação. Ou, ainda, uma lei que, ao censurar os meios de comunicação, possa repercutir negativamente na criação artística.

Neves fala, assim, dos **efeitos colaterais** que as leis produzem.

Portanto, além do **sentido negativo** da legislação simbólica (de ineficácia normativa e vigência social), ela também se apresenta em um **sentido positivo**: produção de **efeitos políticos**, e não propriamente jurídicos.

■ 2.3.3. Constitucionalização simbólica

Marcelo Neves, valendo-se do modelo sistêmico proposto por **Niklas Luhmann**, define a Constituição como “... ‘acoplamento estrutural’ entre **política e direito**. Nessa perspectiva, a Constituição em sentido especificamente moderno apresenta-se como uma via de ‘prestações’ recíprocas e, sobretudo, como mecanismo de **interpenetração** (ou mesmo de interferências) entre dois **sistemas sociais autônomos**, a política e o direito, na medida em que ela ‘possibilita uma solução jurídica do problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico’”.³⁴

Diante desse conceito de *Constituição* (nos termos da teoria dos sistemas de Luhmann), é possível, segundo Neves, associá-lo à noção de **constitucionalização** e, então, enfrentar a problemática da **concretização** das normas constitucionais, analisando a relação entre o texto e a realidade constitucional.

Assim, Marcelo Neves, partindo dos modelos de **Müller** e **Häberle**, define a **constitucionalização simbólica**, também, tanto em sentido negativo como positivo.³⁵

Negativamente, o texto constitucional “não é suficientemente concretizado normativo-juridicamente de forma generalizada”.

Positivamente, “a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham um relevante papel político-ideológico”, servindo para encobrir problemas sociais e obstruindo as transformações efetivas da sociedade.

Em seguida, o autor admite o desenvolvimento adotado para a legislação simbólica também para a **constitucionalização simbólica**, falando, aqui, então, em três formas de manifestações, já estudadas no ponto anterior: a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado (**constitucionalização-álibi**) e c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios.

■ 2.3.4. Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico

Marcelo Neves desenvolve a ideia de constitucionalização simbólica como “alopoiese do direito”, isso quer dizer, “... a reprodução do sistema por critérios, programas e códigos de seu ambiente”,³⁶ e, então, discute a possibilidade de descrever o **direito da sociedade moderna como “autopoiético”**, o que quer dizer, capaz de autoproduzir-se a partir de critérios, programas e códigos de seu próprio ambiente.

Após distinguir os países da sociedade moderna periféricos dos centrais, estabelece que a **constitucionalização simbólica** aparece como uma realidade marcante da modernidade periférica (em razão da desigualdade econômica entre os países) e, nesse sentido, dentro desse contexto, percebe-se uma **hipertrofia da função político-simbólica** em relação à eficácia normativo-jurídica da Constituição (simbólica) nesses países (periféricos).

Constata-se, assim, uma preponderância (ou mais adequadamente uma **sobreposição**) do sistema **político** sobre o **jurídico**, não se percebendo o “acoplamento estrutural” entre os sistemas político e jurídico anteriormente apontado na teoria de Luhmann.

Nesses países, então, como afirma, há um bloqueio do sistema jurídico, havendo uma falta de concretização normativo-jurídica do texto constitucional.

O texto da Constituição é utilizado de acordo com os interesses políticos.

A constitucionalização (simbólica), novamente, funciona como um **álibi**: “o ‘Estado’ apresenta-se como identificado com os valores constitucionais, que não se realizam no presente por ‘culpa’ do subdesenvolvimento da ‘sociedade’. Já na retórica dos grupos interessados em transformações reais nas relações de poder, os quais pretendem frequentemente representar a ‘subcidadania’, invocam-se os direitos proclamados no texto constitucional para denunciar a ‘realidade constitucional inconstitucional’ e atribuir ao Estado/governo dos ‘sobrecidadãos’ a ‘culpa’ pela não realização generalizada dos direitos constitucionais, que seria possível estivesse o Estado/governo em outras mãos...”. [37](#)

Essa problemática, aponta o autor, é verificada não somente no sistema político-jurídico mas, também, nos **sistemas econômico, educacional, de saúde etc.** (remetemos o nosso ilustre leitor para o *capítulo 14* — Direitos Fundamentais, deste nosso estudo).

Por fim, conclui Marcelo Neves que a **constitucionalização simbólica** não seria um “jogo de soma zero”. Isso porque “... proporciona o surgimento de movimentos e organizações sociais envolvidos criticamente na realização dos valores proclamados solenemente no texto constitucional e, portanto, integrados na luta política pela **ampliação da cidadania**”. Ainda, “não se pode excluir a possibilidade, porém, de que a realização dos valores democráticos expressos no documento constitucional pressuponha um momento de ruptura com a ordem de poder estabelecida, com implicações politicamente contrárias à diferenciação e à identidade/autonomia do direito. Isso se torna tanto mais provável à proporção que os procedimentos previstos no texto constitucional sejam deformados no decorrer do processo de concretização e não se operacionalizem como mecanismos estatais de legitimação”. [38](#)

■ 2.3.5. Neoconstitucionalismo, ativismo judicial e a concretização das normas constitucionais

Diante de todo o exposto, percebe-se que a proposta de

constitucionalização simbólica deve ser o ponto de partida para que, compreendendo a problemática, diante das expectativas colocadas, as normas não sirvam apenas como retórica política ou álibi dos governantes.

É preciso identificar os mecanismos de sua **concretização** e, nisso, além do papel da sociedade, parece-nos que o **Judiciário** tem uma importante missão, realizando a implementação da efetividade das normas constitucionais.

Identificamos, como será estudado neste nosso trabalho, uma **nova perspectiva** na utilização das técnicas do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (em relação às normas programáticas) e, assim, a consagração da importante figura do **ativismo judicial**.

Por esse motivo Écio Oto Ramos Duarte³⁹ define o **neoconstitucionalismo** partindo de uma **nova visão da Constituição**, buscando dar a ela **sentido** e, assim, superando o seu caráter meramente retórico, encontrando mecanismos para a real e efetiva concretização de seus preceitos.

■ 2.4. CLASSIFICAÇÃO (TIPOLOGIA)

Como advertimos, qualquer classificação depende de critérios escolhidos pelos estudiosos, não se podendo dizer que um é mais acertado que o outro, talvez mais adequado. Procuraremos trazer à baila os critérios classificatórios que aparecem nos concursos públicos, dada a finalidade deste trabalho. Vejamo-los.

■ 2.4.1. Quanto à origem e a distinção entre “Constituição” e “Carta”

Quanto à origem, as Constituições poderão ser **outorgadas, promulgadas, cesaristas** (ou **bonapartistas**) e **pactuadas** (ou **dualistas**).

Outorgada é a Constituição imposta, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário (grupo, ou governante), que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar. No Brasil, as Constituições outorgadas foram as de 1824 (Império), 1937 (inspirada em modelo fascista, extremamente autoritária

— *Getúlio Vargas*), 1967 (ditadura militar), sendo que alguns chegam inclusive a mencionar como exemplo de outorga a EC n. 1/69 (apesar de tecnicamente impreciso). As Constituições outorgadas recebem, por alguns estudiosos, o “apelido” de *Cartas Constitucionais*.

Conforme veremos ao estudar o *histórico das Constituições*, alguns autores entendem que o texto de 1967 teria sido “promulgado”, já que votado nos termos do art. 1.º, § 1.º, do AI 4/66. Contudo, em razão do “autoritarismo” implantado pelo *Comando Militar da Revolução*, não possuindo o Congresso Nacional liberdade para alterar substancialmente o novo Estado que se instaurava, preferimos dizer que o texto de 1967 foi **outorgado** unilateralmente (apesar de formalmente votado, aprovado e “promulgado”) pelo regime ditatorial militar implantado.

Também entendemos que, dado o seu caráter revolucionário, a EC n. 1/69 pode ser considerada como manifestação de um novo **poder constituinte originário**, imposta pelo governo de “Juntas Militares”, nos termos do AI 12, de 31.08.1969.

Promulgada, também chamada de **democrática, votada** ou **popular**, é aquela Constituição fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, para, em nome dele, atuar, nascendo, portanto, da deliberação da representação legítima popular. Os exemplos são a de 1891 (primeira da República), 1934 (inserindo a democracia social, inspirada na Constituição de Weimar), 1946 e, finalmente, a atual, de 1988, alterada por 6 emendas de revisão e 88 emendas, fruto do poder constituinte derivado reformador, podendo, ainda, com a regra do art. 5.º § 3.º, trazida pela **EC n. 45/2004**, ter os seus direitos e garantias fundamentais ampliados por tratados e convenções internacionais de direitos humanos, os quais, observadas as formalidades, terão equivalência às emendas constitucionais.

Cesarista, segundo José Afonso da Silva, “... não é propriamente outorgada, mas tampouco é democrática, ainda que criada com participação popular”. E continua o mestre definindo-a como aquela “... formada por plebiscito popular sobre um projeto elaborado por um Imperador (plebiscitos napoleônicos)[40](#) ou

um Ditador (plebiscito de Pinochet, no Chile). A participação popular, nesses casos, não é democrática, pois visa apenas ratificar a **vontade do detentor do poder**. Não destacamos esse tipo no esquema porque bem pode ser considerado um modo de outorga por interposta pessoa”.⁴¹ Complementando, cabe acrescentar que a participação popular pode dar-se não apenas por *plebiscito* como, também, na hipótese de ratificação, por **referendo**, já que este se caracteriza como instrumento de confirmação das decisões políticas e governamentais, ou seja, toma-se a decisão para, posteriormente, levar-se a referendo popular.

Nesse caso, contudo, “... os referendos são utilizados como um instrumento de **autocracia** (regime do chefe), e não da democracia, pois geralmente nem todas as correntes ideológicas participam do debate e não se concede liberdade para uma efetiva discussão ou para eventual rejeição das propostas”.⁴²

Pactuada, também pouco cobrada nos concursos. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, as Constituições pactuadas “... surgem através de um pacto, são aquelas em que o poder constituinte originário se concentra nas mãos de mais de um titular. Por isso mesmo, trata-se de modalidade anacrônica, dificilmente ajustando-se à noção moderna de Constituição, intimamente associada à ideia de unidade do poder constituinte. Tais Constituições pactuadas foram bastante difundidas no seio da monarquia estamental da Idade Média, quando o poder estatal aparecia cindido entre o monarca e as ordens privilegiadas. Exemplificam-nas a Magna Carta de 1215, que os barões ingleses obrigam João Sem Terra a jurar”.⁴³

Para Bonavides, “a Constituição **pactuada** é aquela que exprime um compromisso instável de duas forças políticas rivais: a realeza absoluta debilitada, de uma parte, e a nobreza e a burguesia, em franco progresso, doutra. Surge então como termo dessa relação de equilíbrio a forma institucional da monarquia limitada. Entendem alguns publicistas que as Constituições pactuadas assinalam o momento histórico em que determinadas classes disputam ao rei um certo grau de participação política, em nome da comunidade, com o propósito de resguardar direitos e amparar franquias adquiridas. Na Constituição pactuada o

equilíbrio é precário. Uma das partes se acha sempre politicamente em posição de força. O pacto selado juridicamente mal encobre essa situação de fato, ‘e o contrato se converte por conseguinte numa estipulação unilateral camuflada’, conforme se deu com a Magna Carta ou a Constituição francesa de 1791: ali a supremacia dos barões; aqui, a supremacia dos representantes da Nação reunidos em assembleia constituinte”.[44](#)

E qual a diferença entre “**Constituição**” e “**Carta**”?

De modo geral, **Constituição** é o *nomen juris* que se dá à Lei Fundamental **promulgada**, democrática ou popular, que teve a sua origem em uma Assembleia Nacional Constituinte. Já **Carta** é o nome reservado para aquela Constituição **outorgada**, imposta de maneira unilateral pelo agente revolucionário mediante ato arbitrário e ilegítimo.

■ 2.4.2. Quanto à forma

Quanto à forma, as Constituições podem ser **escritas (instrumental)** ou **costumeiras (não escritas ou consuetudinárias)**.

Escrita (instrumental), o próprio nome nos ajuda a explicar, seria a Constituição formada por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo as normas fundamentais de um Estado. Como exemplo, citamos a brasileira de 1988, a portuguesa, a espanhola etc.

Nesse particular, cabe alertar que, no direito brasileiro, vêm sendo encontrados textos escritos com natureza de Constituição (não se resumindo a um único código), por exemplo, nos termos do art. 5.º, § 3.º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros e que, dessa maneira, passam a ser equivalentes às emendas constitucionais. Por isso, parece interessante a ideia, apesar de tímida, de uma **Constituição legal** (Constituição escrita e que se apresenta esparsa ou fragmentada em textos, conforme apontou Paulo Bonavides — cf. *item 2.3.7*).

Costumeira (não escrita ou consuetudinária) seria aquela Constituição que,

ao contrário da escrita, não traz as regras em um único texto solene e codificado. É formada por “textos” esparsos, reconhecidos pela sociedade como fundamentais, e baseia-se nos usos, costumes, jurisprudência, convenções. Exemplo clássico é a Constituição da Inglaterra.

A doutrina observa que “hoje, contudo, mesmo a Inglaterra (exemplo normalmente lembrado de país regido por uma Constituição não escrita) assenta princípios constitucionais em textos escritos, em que pesem os costumes formarem relevantes valores constitucionais”.⁴⁵

A classificação propõe, então, a utilização do conceito de *costumeira* em um sentido mais aberto, pois, como bem anota Paulo Bonavides, “na época contemporânea **inexistem Constituições totalmente costumeiras**, semelhantes àquela que teve a França no *ancien régime*, antes da Revolução Francesa de 1789, ou seja, ‘uma complexa massa de costumes, usos e decisões judiciais’ (Barthélemy)”.

Por esse motivo Bonavides prefere classificar a experiência inglesa como sendo a de uma *Constituição não totalmente costumeira* ou, melhor dizendo, uma **Constituição parcialmente costumeira**, já que as “... leis abrangem o direito estatutário (*statute law*), o direito casuístico ou jurisprudencial (*case law*), o costume, mormente o de natureza parlamentar (*Parliamentary custom*) e as convenções constitucionais (*constitutional conventions*)”.⁴⁶

Quanto à norte-americana de 1787, Bonavides a define como **escrita**, porém **complementada** pelos **costumes**, sendo que “... o elemento consuetudinário entra igualmente como fator auxiliar e subsidiário importantíssimo para completar e corrigir o texto constitucional lacunoso ou suprir, pela interpretação, partes obscuras e controversas da Constituição”. Lembrando Carl J. Friedrich, destaca que a norte-americana é completada pela **doutrina da revisão judicial** (precedentes judiciais) e, além disso, as normas escritas “... têm que ser sumamente flexíveis, porque é impossível regulamentar com absoluta precisão as eventualidades do futuro”.⁴⁷

■ 2.4.3. Quanto à extensão

Quanto à extensão, podem as Constituições ser **sintéticas (concisas, breves, sumárias, sucintas, básicas)** ou **analíticas (amplas, extensas, largas, prolixas, longas, desenvolvidas, volumosas, inchadas)**.

Sintéticas seriam aquelas enxutas, veiculadoras apenas dos princípios fundamentais e estruturais do Estado. Não descem a minúcias, motivo pelo qual são mais duradouras, na medida em que os seus princípios estruturais são interpretados e adequados aos novos anseios pela atividade da Suprema Corte. O exemplo lembrado é a Constituição americana, que está em vigor há mais de 200 anos (é claro, com emendas e interpretações feitas pela Suprema Corte).

Pinto Ferreira, analisando o constitucionalismo pátrio, indica a Constituição de 1891 como exemplo de sintética. [48](#)

Paulo Bonavides, a seu turno, e com precisão, observa que “as Constituições concisas ou breves resultam numa **maior estabilidade** do arcabouço constitucional, bem como numa flexibilidade que permite adaptar a Constituição a situações novas e imprevistas do desenvolvimento institucional de um povo, a suas variações mais sentidas de ordem política, econômica e financeira, a necessidades, sobretudo, de improvisar soluções que poderiam, contudo, esbarrar na rigidez dos obstáculos constitucionais”. [49](#)

Analíticas, por outro lado, são aquelas que abordam todos os assuntos que os representantes do povo entenderem fundamentais. Normalmente descem a minúcias, estabelecendo regras que deveriam estar em leis infraconstitucionais, como, conforme já mencionamos, o art. 242, § 2.º, da CF/88, que dispõe que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Assim, o clássico exemplo é a brasileira de 1988.

Segundo Bonavides, “as Constituições se fizeram desenvolvidas, volumosas, inchadas, em consequência principalmente de duas causas: a preocupação de dotar certos institutos de proteção eficaz, o sentimento de que a rigidez constitucional é anteparo ao exercício discricionário da autoridade, o anseio de conferir estabilidade ao direito legislado sobre determinadas matérias e, enfim, a conveniência de atribuir ao Estado, através do mais alto instrumento jurídico que é a Constituição, os encargos indispensáveis à manutenção da paz social”. [50](#)

■ 2.4.4. Quanto ao conteúdo

O conceito de Constituição pode ser tomado tanto em sentido **material** como **formal**.

Materialmente constitucional será aquele texto que contiver as normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Como exemplo podemos citar a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que, em seu art. 178, prescrevia ser constitucional somente o que dissesse respeito aos limites e atribuições respectivos dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não fosse constitucional poderia ser alterado, sem as formalidades referidas (nos arts. 173 a 177), pelas legislaturas ordinárias.

Formal, por seu turno, será aquela Constituição que elege como critério o processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer regra nela contida terá o caráter de constitucional. A brasileira de 1988 é **formal!**

Cumpra observar (*e este tema ainda não está fechado*) que, com a introdução do § 3.º no art. 5.º, pela **EC n. 45/2004**, passamos a ter uma espécie de **conceito misto**, já que a nova regra só confere a natureza de emenda constitucional (*norma formalmente constitucional*) aos tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** (*matéria*), desde que observadas as **formalidades de aprovação** (*forma*).

Como se sabe (e voltaremos a essa análise), nos termos do art. 5.º, § 3.º, “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

Nesse sentido, podemos lembrar o **Decreto Legislativo n. 186/2008**, que aprova o texto da *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* e de seu *Protocolo Facultativo*, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgados pelo **Decreto n. 6.949, de 25.08.2009**, tendo sido, assim, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de norma

constitucional.

■ 2.4.5. Quanto ao modo de elaboração

Quanto ao modo de elaboração as Constituições poderão ser **dogmáticas** (também denominadas “*sistemáticas*”, segundo J. H. Meirelles Teixeira) ou **históricas**.

Dogmáticas, sempre escritas, consubstanciam os dogmas estruturais e fundamentais do estado ou, como bem observou Meirelles Teixeira, “... partem de teorias preconcebidas, de planos e sistemas prévios, de ideologias bem declaradas, de dogmas políticos... São elaboradas de um só jato, reflexivamente, racionalmente, por uma Assembleia Constituinte”.⁵¹ Como exemplo, destacamos a brasileira de 1988.

Históricas, constituem-se através de um lento e contínuo processo de formação, ao longo do tempo, reunindo a história e as tradições de um povo. Aproximam-se, assim, da costumeira e têm como exemplo a Constituição inglesa.

■ 2.4.6. Quanto à alterabilidade

Esse critério recebe diversas denominações pelos constitucionalistas pátrios. Além da citada *alterabilidade* (Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky⁵²), encontramos: *mutabilidade* (Michel Temer;⁵³ Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior⁵⁴), *estabilidade* (José Afonso da Silva⁵⁵ e Alexandre de Moraes⁵⁶) e *consistência* (Pinto Ferreira⁵⁷).

Em essência, deixando de lado a questão terminológica, as Constituições poderão ser **rígidas**, **flexíveis** (também chamadas de **plásticas**, segundo a denominação de Pinto Ferreira)⁵⁸ e **semirrígidas** (ou **semiflexíveis**). Alguns autores ainda lembram as **fixas** ou **silenciosas**, as **transitoriamente flexíveis**, as **imutáveis** (**permanentes**, **graníticas** ou **intocáveis**) e as **super-rígidas**.

Rígidas são aquelas Constituições que exigem, para a sua alteração (daí

preferirmos a terminologia *alterabilidade*), um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das normas não constitucionais. Lembramos que, à exceção da Constituição de 1824 (considerada semirrígida), todas as Constituições brasileiras foram, inclusive a de 1988, rígidas!

A rigidez constitucional da CF/88 está prevista no art. 60, que, por exemplo, em seu § 2.º estabelece um *quorum* de votação de 3/5 dos membros de cada Casa, em dois turnos de votação, para aprovação das emendas constitucionais. Em contraposição, apenas para aclarar mais a situação lembrada, a votação das leis ordinárias e complementares dá-se em um único turno de votação (art. 65), com *quorum* de maioria simples (art. 47) e absoluta (art. 69), respectivamente para lei ordinária e complementar. Outra característica definidora da rigidez da CF/88 está prevista nos incisos I, II e III do art. 60, que estabelecem iniciativa restrita: *a)* de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; *b)* do Presidente da República; e *c)* de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela *maioria relativa* de seus membros, enquanto a iniciativa das leis complementares e ordinárias é geral, de acordo com o art. 61. [59](#)

Flexíveis são aquelas Constituições que não possuem um processo legislativo de alteração mais dificultoso do que o processo legislativo de alteração das normas infraconstitucionais. Vale dizer, a dificuldade em alterar a Constituição é a mesma encontrada para alterar uma lei que não é constitucional.

Nesse sentido, do ponto de vista formal, devemos observar que, em se tratando de **Constituição flexível**, não existe hierarquia entre Constituição e lei infraconstitucional, ou seja, uma lei infraconstitucional posterior altera texto constitucional se assim expressamente o declarar, quando for com ele incompatível, ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a Constituição.

Semiflexíveis ou **semirrígidas** são aquelas Constituições tanto rígidas como flexíveis, ou seja, algumas matérias exigem um processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para alteração das leis infraconstitucionais, enquanto

outras não requerem tal formalidade. O exemplo sempre lembrado é o da Constituição Imperial de 1824, que, em seu art. 178, dizia: “É só constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e individuais dos cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, pode ser alterado, sem as formalidades referidas, pelas legislaturas ordinárias”.

As **fixas**, segundo Kildare Gonçalves Carvalho, “... são aquelas que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual àquele que as criou, isto é, o poder constituinte originário. São conhecidas como **constituições silenciosas**, porque não estabelecem, expressamente, o procedimento para sua reforma. Têm valor apenas histórico, sendo exemplos destas Constituições o Estatuto do Reino da Sardenha, de 1848, e a Carta Espanhola de 1876”.[60](#)

Para Bulos, as **Constituições transitoriamente flexíveis** “... são as suscetíveis de reforma, com base no mesmo rito das leis comuns, mas apenas por determinado período; ultrapassado este, o documento constitucional passa a ser rígido. Nessa hipótese, o binômio rigidez/flexibilidade não coexiste simultaneamente. Apresenta-se de modo alternado...”. Como exemplo, o autor lembra a Constituição de Baden de 1947 e a Carta irlandesa de 1937 durante os primeiros três anos de vigência.[61](#)

Imutáveis seriam aquelas Constituições inalteráveis, verdadeiras *reliquias históricas*[62](#) e que se pretendem eternas, sendo também denominadas **permanentes, graníticas** ou **intocáveis**.

Finalmente, segundo Alexandre de Moraes, a brasileira de 1988 seria exemplo de Constituição **super-rígida**, já que, além de possuir um processo legislativo diferenciado para a alteração de suas normas (rígida), excepcionalmente, algumas matérias apresentam-se como **imutáveis** (cláusulas pétreas, art. 60, § 4.º).[63](#)

Esta última classificação, contudo, **não parece ser a posição adotada pelo STF**, que tem admitido a alteração de matérias contidas no art. 60, § 4.º, desde que a reforma não tenda a abolir os preceitos ali resguardados e dentro de uma ideia de razoabilidade e ponderação. Foi o caso da **reforma da previdência** que

admitiu a **taxação dos inativos**, mitigando, assim, os direitos e garantias individuais (as situações já consolidadas das pessoas aposentadas que passaram a ser taxadas). [64](#)

■ 2.4.7. Quanto à sistemática (critério sistemático)

Valendo-se do **critério sistemático**, Pinto Ferreira divide as Constituições em **reduzidas** (ou **unitárias**) e **variadas**. [65](#)

Reduzidas seriam aquelas que se materializariam em um só código básico e sistemático, como as brasileiras (ver crítica a seguir).

Variadas seriam aquelas que se distribuiriam em vários textos e documentos esparsos, sendo formadas de várias leis constitucionais, destacando-se a belga de 1830 e a francesa de 1875.

Nesse mesmo sentido, Bonavides distingue as Constituições **codificadas** das **legais**.

Codificadas (que correspondem às *reduzidas* de Pinto Ferreira) seriam “... aquelas que se acham contidas inteiramente num só texto, com os seus princípios e disposições sistematicamente ordenados e articulados em títulos, capítulos e seções, formando em geral um único corpo de lei”.

Por sua vez, as **legais** (também denominadas **Constituições escritas não formais**, e que equivalem às *variadas* de Pinto Ferreira) seriam aquelas “... escritas que se apresentam esparsas ou fragmentadas em vários textos. Haja vista, a título ilustrativo, a Constituição francesa de 1875. Compreendia ela Leis Constitucionais, elaboradas em ocasiões distintas de atividade legislativa, como as leis de estabelecimento dos poderes públicos, de organização do Senado e de relações entre os poderes. Tomadas em conjunto passaram a ser designadas como a Constituição da Terceira República”. [66](#)

A **brasileira de 1988**, em um primeiro momento, como aponta Pinto Ferreira, seria **reduzida**, **codificada** ou **unitária**.

Contudo, especialmente diante da ideia de “bloco de constitucionalidade”, que será estudada no *item 6.7.1.3*, parece **caminharmos** (de maneira muito tímida,

ainda) para um critério que se aproxima de Constituição **esparsa** (legal ou escrita não formal — escrita e que se apresenta fragmentada em vários textos), especialmente diante da regra contida no art. 5.º, § 3.º, que admite a constitucionalização dos tratados ou convenções internacionais de direitos humanos que forem incorporados com o *quorum* e procedimento das emendas constitucionais.

Conforme vimos, destacamos o **Decreto Legislativo n. 186/2008** que aprova o texto da *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* e de seu *Protocolo Facultativo*, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgados pelo **Decreto n. 6.949, de 25.08.2009**, tendo sido, assim, incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de norma constitucional.

Ainda, existem vários artigos de **emendas constitucionais** que não foram introduzidos no “corpo” da Constituição e, permanecendo como artigo autônomo das emendas, sem dúvida, têm **natureza constitucional** e, portanto, eventual lei que contrarie artigo de emenda constitucional poderá ser declarada inconstitucional, servindo a emenda como paradigma de confronto.

Cabe alertar, contudo, que apesar dessa percepção, de modo geral, as provas de concursos vêm definindo a brasileira de 1988 como **reduzida**.

■ 2.4.8. Quanto à dogmática

No tocante à **dogmática**, Pinto Ferreira, valendo-se do **critério ideológico** e lembrando as lições de **Paulino Jacques**, identifica tanto a Constituição **ortodoxa** como a **eclética**.

Ortodoxa é aquela formada por uma só ideologia, por exemplo, a soviética de 1977, hoje extinta, e as diversas Constituições da China marxista.

Eclética seria aquela formada por ideologias conciliatórias, como a brasileira de 1988 ou a da Índia de 1949.

Nessa linha, alguns autores aproximam a eclética da **compromissória**. De fato, parece possível dizer que a **brasileira de 1988 é compromissória**, assim

como a portuguesa de 1976.

Nas palavras de Canotilho, “numa sociedade plural e complexa, a Constituição é sempre um produto do ‘pacto’ entre forças políticas e sociais. Através de ‘barganha’ e de ‘argumentação’, de ‘convergência’ e ‘diferenças’, de cooperação na deliberação mesmo em caso de desacordos persistentes, foi possível chegar, no procedimento constituinte, a um *compromisso constitucional* ou, se preferirmos, a vários ‘compromissos constitucionais’. O **carácter compromissório da Constituição de 1976** representa uma **força** e não uma debilidade. Mesmo quando se tratava de ‘conflitos profundos’ (*deep conflict*), houve a possibilidade de se chegar a bases normativas razoáveis. Basta referir o compromisso entre o princípio liberal e o princípio socialista, o compromisso entre uma visão personalista-individual dos direitos, liberdades e garantias e uma perspectiva dialético-social dos direitos económicos, sociais e culturais, o compromisso entre ‘legitimidade eleitoral’ e ‘legitimidade revolucionária’, o compromisso entre princípio da unidade do Estado e o princípio da autonomia regional e local, o compromisso entre democracia representativa e democracia participativa”.⁶⁷

■ 2.4.9. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência)

Karl Loewenstein distinguiu as Constituições **normativas, nominalistas (nominativas ou nominais)** e **semânticas**. Trata-se do **critério ontológico**, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional.

Segundo Pinto Ferreira, “as *Constituições normativas* são aquelas em que o processo de poder está de tal forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu controle procedimental. As *Constituições nominalistas* contêm disposições de limitação e controle de dominação política, sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e com insuficiente concretização constitucional. Enfim,

as *Constituições semânticas* são simples reflexos da realidade política, servindo como mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem limitação do seu conteúdo”.[68](#)

Isso quer dizer que da **normativa** à **semântica** percebemos uma gradação de **democracia e Estado Democrático de Direito** para **autoritarismo**.

Enquanto nas **Constituições normativas** a pretendida limitação ao poder se implementa na prática, havendo, assim, correspondência com a realidade, nas **nominalistas** busca-se essa concretização, porém, sem sucesso, não se conseguindo uma verdadeira normatização do processo real do poder. Nas **semânticas**, por sua vez, nem sequer se tem essa pretensão, buscando-se conferir legitimidade meramente formal aos detentores do poder, em seu próprio benefício.

Para Guilherme Peña de Moraes, ao tratar do constitucionalismo pátrio, **a brasileira de 1988 “pretende ser” normativa**; as de 1824, 1891, 1934 e 1946 foram nominais (“... a Constituição é dotada de um aspecto educativo e prospectivo (...). Portanto, embora não haja concordância entre as normas constitucionais e a realidade política no presente, há a aspiração de que tal desiderato seja alcançado no futuro”). E as de 1937, 1967 e a EC n. 1/69 foram semânticas.[69](#)

Marcelo Neves, fazendo uma releitura de Loewenstein, prefere denominar as semânticas **instrumentalistas**, já que instrumentos dos detentores do poder. Em sua opinião, o texto de 1988 seria **nominalista**, servindo como verdadeiro “álibi” para os governantes (no tocante à não concretização de seus preceitos), ao passo que as instrumentalistas (1937, 1967 e a EC n. 1/69) aparecem como “armas” na “luta política”.[70](#)

■ 2.4.10. Quanto ao sistema

Segundo *Diogo de Figueiredo Moreira Neto*, a Constituição, quanto ao **sistema**, pode ser classificada em **principiológica** ou **preceitual**.

Na **principiológica**, conforme anotou Guilherme Peña de Moraes, “...

predominam os **princípios**, identificados como normas constitucionais providas de alto grau de abstração, consagradores de valores, pelo que é necessária a mediação concretizadora, tal como a Constituição brasileira”.

Por seu turno, na **preceitual** “... prevalecem as **regras**, individualizadas como normas constitucionais revestidas de pouco grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo que é possível a aplicação coercitiva, tal como a Constituição mexicana”.⁷¹

■ 2.4.11. Quanto à função

Quanto à função, as Constituições podem ser classificadas como **provisórias** ou **definitivas**.

De acordo com Jorge Miranda, “chama-se de *pré-Constituição*, *Constituição provisória* ou, sob outra ótica, *Constituição revolucionária* ao conjunto de normas com a dupla finalidade de definição do regime de elaboração e aprovação da Constituição formal e de estruturação do poder político no interregno constitucional, a que se acrescenta a função de eliminação ou erradicação de resquícios do antigo regime. Contrapõe-se à Constituição *definitiva* ou de *duração indefinida para o futuro* como pretende ser a Constituição produto final do processo constituinte”.⁷²

■ 2.4.12. Quanto à origem de sua decretação: heterônomas (heteroconstituições) x autônomas (“autoconstituições” ou “homoconstituições”)

Quando surge um novo Estado, ou o Estado que já existia restaura-se, ou sofre radical transformação de sua estrutura, essa nova manifestação atrela-se a uma Constituição material que já vem acompanhada da Constituição formal, ou que passa a ter uma Constituição formal estabelecida em momento seguinte.

A soberania do Estado está sedimentada na Constituição material, e a Constituição formal, normalmente, provém do próprio Estado.

De modo **incomum**, contudo, a doutrina identifica Constituições que foram decretadas de fora do Estado por outro (ou outros) Estado(s) ou por organizações internacionais.

Estamos diante daquilo que *Miguel Galvão Teles* denominou **heteroconstituição**.⁷³

Conforme anota Jorge Miranda, além da **raridade**, causam certa **perplexidade**, dando como exemplo: “... algumas das Constituições, ou das primeiras Constituições, dos **países da Commonwealth** aprovadas por leis do Parlamento britânico (Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Jamaica, Maurícia, etc.), a primeira Constituição da **Albânia** (obra de uma conferência internacional, de 1913) ou a Constituição **cipriota** (procedente dos acordos de Zurique, de 1960, entre a Grã-Bretanha, a Grécia e a Turquia) ou a Constituição da **Bósnia-Herzegovina** (após os chamados acordos de Dayton de 1995)”, ou, ainda, no **plano puramente político**, “as Constituições surgidas por **imposição** de outros Estados: as Constituições das **Repúblicas Helvética e Batava** do tempo da Revolução francesa, a Constituição **espanhola** de **1808**, as **primeiras** Constituições da **Libéria** e das **Filipinas**, a Constituição **japonesa** de **1946**, as **Constituições das democracias populares do leste da Europa dos anos 40 e 50**, a **primeira** Constituição da **Guiné Equatorial**. E por imposição das Nações Unidas: as Constituições da **Namíbia** de **1990** e de **Camboja** de **1993**”.⁷⁴

Interessante observar, como ensina o mestre português, que “... até a independência o fundamento de validade da Constituição estava na ordem jurídica donde proveio; com a independência transfere-se para a ordem jurídica local, investida de poder constituinte. Verifica-se, pois, uma verdadeira **novação** do **ato constituinte** ou (doutro prisma) uma **deslocação da regra de reconhecimento**; e **apenas** o **texto** que persista — correspondente a Constituição em sentido instrumental — **se liga à primitiva fonte, não o valor vinculativo das normas**”.⁷⁵

Diante do exposto, no entanto, pode-se afirmar que as Constituições brasileiras **não são heterônomas**, na medida em que elaboradas e decretadas dentro do próprio Estado que irão reger. Podemos, assim, denominá-las, nesse

sentido, Constituições **autônomas**, ou **autoconstituições**, ou, por que não, **homoconstituições** (fazendo um contraponto à terminologia proposta por *Miguel Galvão Teles*).

■ 2.4.13. Constituições garantia, balanço e dirigente (Manoel Gonçalves Ferreira Filho)

A Constituição **garantia** busca garantir a liberdade, limitando o poder; a **balanço** reflete um degrau de evolução socialista e a **dirigente** estabelece um projeto de Estado (ex.: portuguesa).

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “modernamente, é frequente designar a Constituição de tipo clássico de *Constituição-garantia*, pois esta visa a garantir a liberdade, limitando o poder. Tal referência se desenvolveu pela necessidade de contrapô-la à *Constituição-balanço*. Esta, conforme a doutrina soviética que se inspira em Lassalle, é a Constituição que descreve e registra a organização política estabelecida. Na verdade, segundo essa doutrina, a Constituição registraria um estágio das relações de poder. Por isso é que a URSS, quando alcançado novo estágio na marcha para o socialismo, adotaria nova Constituição, como o fez em 1924, 1936 e em 1977. Cada uma de tais Constituições faria o *balanço* do novo estágio. Hoje muito se fala em *Constituição-dirigente*. Esta seria a Constituição que estabeleceria um *plano* para dirigir uma evolução política. Ao contrário da *Constituição-balanço* que refletiria o presente (o ser), a *Constituição-programa* anunciaria um *ideal* a ser concretizado. Esta *Constituição-dirigente* se caracterizaria em consequência de *normas programáticas* (que para não caírem no vazio reclamariam a chamada *inconstitucionalidade por omissão*...). A ideia de *Constituição-dirigente* é sobretudo encarecida por juristas de inspiração marxista, como o português Canotilho, que desejam prefigurar na Constituição a implantação progressiva de um Estado socialista, primeiro, comunista, a final. Exemplo, a Constituição portuguesa de 1976”. [76](#)

■ 2.4.14. Constituições liberais (negativas) e sociais (dirigentes) — conteúdo ideológico das Constituições (André Ramos Tavares)

André Ramos Tavares propõe outra classificação, levando em conta o conteúdo ideológico das Constituições, classificando-as em **liberais** (ou **negativas**) e **sociais** (ou **dirigentes**).⁷⁷

Para ele, “as Constituições **liberais** surgem com o triunfo da ideologia burguesa, com os ideais do liberalismo”.

Nesse contexto, destacamos os direitos humanos de **1.ª dimensão** e, assim, a ideia da não intervenção do Estado, bem como a proteção das liberdades públicas. Poderíamos falar, portanto, em **Constituições negativas** (absenteísmo estatal).

Por outro lado, as Constituições **sociais** refletem um momento posterior, de necessidade da atuação estatal, consagrando a igualdade substancial, bem como os direitos sociais, também chamados de direitos de **2.ª dimensão**.

Trata-se da percepção de uma **atuação positiva** do Estado e, por isso, André Ramos Tavares aproxima as Constituições sociais da ideia de **dirigismo** estatal sugerida por Canotilho.

Segundo o autor, estamos diante do **Estado do Bem Comum**. E completa: “é bastante comum, nesse tipo de Constituição, traçar expressamente os grandes objetivos que hão de nortear a atuação governamental, impondo-os (ao menos a longo prazo)”.

■ 2.4.15. Raul Machado Horta (Constituições expansivas)

Raul Machado Horta⁷⁸ inscreve a brasileira de 1988 no grupo das **Constituições expansivas**. Para o ilustre autor, “a expansividade da Constituição de 1988, em função dos temas novos e da ampliação conferida a temas permanentes, como no caso dos Direitos e Garantias Fundamentais, pode ser aferida em três planos distintos.” *conteúdo anatômico e estrutural da Constituição; comparação constitucional interna e comparação constitucional*

externa:

■ **conteúdo anatômico e estrutural da Constituição:** destacam-se a estruturação do texto e sua divisão em títulos, capítulos, seções, subseções, artigos da parte permanente e do ADCT;

RAUL MACHADO HORTA— CONSTITUIÇÃO EXPANSIVA— CONTEÚDO ANATÔMICO E ESTRUTURAL DACF/88	
■ Preâmbulo	
■ Título I — Dos Princípios Fundamentais — arts. 1.º a 4.º	
■ Título II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais — arts. 5.º a 17	
■ Título III — Da Organização do Estado — arts. 18 a 43	
■ Título IV — Da Organização dos Poderes — arts. 44 a 135	
■ Título V — Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas — arts. 136 a 144	
■ Título VI — Da Tributação e do Orçamento — arts. 145 a 169	
■ Título VII — Da Ordem Econômica e Financeira — arts. 170 a 192	
■ Título VIII — Da Ordem Social — arts. 193 a 232	
■ Título IX — Das Disposições Constitucionais Gerais — arts. 233 a 250	

■ **comparação constitucional interna:** relaciona-se a CF/88 com as Constituições brasileiras precedentes, considerando a extensão de cada uma e as suas alterações. Segundo o autor, referida *comparação interna* “... registra a dilatação da matéria constitucional e a evolução das Constituições brasileiras no tempo”;

■ **comparação constitucional externa:** relaciona a Constituição brasileira com as Constituições estrangeiras mais extensas.

Dentro dessa ideia, bastante interessante a proposta defendida por Luiz Sales do Nascimento, de uma *teoria científica do direito constitucional comparado*, sugerindo que a atividade comparativa siga verdadeiro e seguro *roteiro metodológico*.⁷⁹

■ 2.4.16. A Constituição Federal brasileira de 1988

Valendo-nos de todos os critérios classificatórios anteriormente expostos e a seguir esquematizados, podemos dizer que a Constituição brasileira de 1988 singulariza-se por ser: **promulgada, escrita, analítica, formal** (cf. nova perspectiva classificatória decorrente do art. 5.º, § 3.º, introduzido pela EC n. 45/2004, sugerida no *item 2.4.4*), **dogmática, rígida, reduzida, eclética, pretende ser normativa, principiológica, definitiva** (ou de **duração indefinida para o futuro**), **autônoma** (**autoconstituição** ou “**homoconstituição**”), **garantia, dirigente, social e expansiva**.

■ *quanto à origem:* outorgada, **promulgada**, cesarista (bonapartista) ou pactuada (dualista);

■ *quanto à forma:* **escrita (instrumental)** ou costumeira (consuetudinária, não escrita);

■ *quanto à extensão:* sintética (concisa, breve, sumária, sucinta, básica)

ou **analítica (ampla, extensa, larga, prolixa, longa, desenvolvida, volumosa, inchada)**;

■ *quanto ao conteúdo*: **formal** ou material (tendência para um critério **misto** — EC n. 45/2004);

■ *quanto ao modo de elaboração*: **dogmática (sistemática)** ou histórica;

■ *quanto à alterabilidade*: **rígida**, flexível, semirrígida (semiflexível), fixa (silenciosa), transitoriamente flexível, imutável (permanente, granítica, intocável), “super-rígida”;

■ *quanto à sistemática (Pinto Ferreira)*: **reduzida (unitária)** ou variada;

■ *quanto à dogmática (Paulino Jacques)*: ortodoxa ou **eclética** (destaque para o caráter **compromissório** do texto de 1988);

■ *quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência — Karl Loewenstein)*: **normativa (pretende ser)**, nominalista ou semântica;

■ *quanto ao sistema*: **principiológica** ou preceitual;

■ *quanto à função*: pré-Constituição, Constituição provisória, ou Constituição revolucionária, e Constituição **definitiva**, ou de **duração indefinida para o futuro**;

■ *quanto à origem de sua decretação*: heterônoma (“heteroconstituição”) ou **autônoma** (“**autoconstituição**” ou “**homoconstituição**”);

■ *Manoel Gonçalves Ferreira Filho*: **garantia**, balanço e **dirigente**;

■ *André Ramos Tavares (conteúdo ideológico das Constituições)*: liberais (negativas) e **sociais (dirigentes)**;

■ *Raul Machado Horta*: **expansiva**.

■ 2.5. ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

Não obstante encontremos na Constituição um todo orgânico e sistematizado, as normas constitucionais estão agrupadas em títulos, capítulos e seções, com conteúdo, origem e finalidade diversos.

Esses dispositivos, trazendo valores distintos, caracterizam a natureza **polifacética** da Constituição, fazendo com que a doutrina agrupe as diversas normas de acordo com a sua finalidade, surgindo, então, o que se denominou **elementos da Constituição**.

A doutrina diverge em relação aos elementos da Constituição.⁸⁰ No entanto, parece ser mais completa a identificação do Professor José Afonso da Silva, de **cinco categorias de elementos**, assim definidas:⁸¹

■ **elementos orgânicos:** normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder. Exemplos: *a)* Título III (Da Organização do Estado); *b)* Título IV (Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo); *c)* Capítulos II e III do Título V (Das Forças Armadas e da Segurança Pública); *d)* Título VI (Da Tributação e do Orçamento);

■ **elementos limitativos:** manifestam-se nas normas que compõem o elenco dos direitos e garantias fundamentais (direitos individuais e suas garantias, direitos de nacionalidade e direitos políticos e democráticos), limitando a atuação dos poderes estatais. Exemplo: Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), excetuando o Capítulo II do referido Título II (Dos Direitos Sociais), estes últimos definidos como elementos socioideológicos;

■ **elementos socioideológicos:** revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social, intervencionista. Exemplos: *a)* Capítulo II do Título II (Dos Direitos Sociais); *b)* Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira); *c)* Título VIII (Da Ordem Social);

■ **elementos de estabilização constitucional:** consubstanciados nas normas constitucionais destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Constituem instrumentos de defesa do Estado e buscam garantir a paz social. Exemplos: *a)* art. 102, I, “a” (ação de inconstitucionalidade); *b)* arts. 34 a 36 (Da intervenção nos Estados e Municípios); *c)* arts. 59, I, e 60 (Processos de emendas à Constituição); *d)* arts. 102 e 103 (Jurisdição constitucional); *e)* Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, especialmente o Capítulo I, que trata do estado de defesa e do estado de sítio, já que os Capítulos II e III

do Título V caracterizam-se como elementos orgânicos);

■ **elementos formais de aplicabilidade:** encontram-se nas normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições. Exemplos: *a)* preâmbulo; *b)* disposições constitucionais transitórias; *c)* art. 5.º, § 1.º, quando estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

■ 2.6. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS [82](#)

CONSTITUIÇÃO	SURGIMENTO	VIGÊNCIA EM ANOS 83
1824	25.03.1824 84	65
1891	24.02.1891 85	39
1934	16.07.1934	03
1937	10.11.1937	08
1946	18.09.1946	20
1967	24.01.1967	02
EC n. 1/1969 86	17.10.1969	18
1988	05.10.1988	26 87

■ 2.6.1. Constituição de 1824

Em 1808, tendo em vista a ocupação das terras portuguesas pelas tropas napoleônicas, a Família Real Portuguesa se transfere para o Brasil, passando a colônia brasileira a ser designada *Reino Unido a Portugal e Algarves*.

Em seguida, em decorrência da *Revolução do Porto* e por exigência dos

nobres portugueses, o Rei Dom João VI, rei de Portugal, retorna a Lisboa em abril de 1821, deixando no Brasil D. Pedro de Alcântara, Príncipe Real do Reino Unido e Regente brasileiro (seu filho com a imperatriz D. Carlota Joaquina).

Esses acontecimentos, sem dúvida, contribuíram para a intensificação dos movimentos pela independência do Brasil, e, em 9 de janeiro de 1822, desrespeitando ordem da Corte portuguesa, que exigia seu retorno imediato na tentativa de efetivar a recolonização brasileira, D. Pedro I, tendo recebido diversas assinaturas coletadas pelos “liberais radicais”, disse: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico” (“**Dia do Fico**”).

Após ter declarado a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I convoca, em 1823, uma *Assembleia Geral Constituinte e Legislativa*, com **ideais marcadamente liberais**, que, contudo, vem a ser dissolvida, arbitrariamente, tendo em vista a existência de divergências com os seus ideais e pretensões autoritários.

Em substituição (da Assembleia Constituinte), D. Pedro I cria um *Conselho de Estado* para tratar dos “negócios de maior monta” e elaborar um novo projeto em total consonância com a sua vontade de “Majestade Imperial”.

A Constituição Política do Império do Brasil foi **outorgada** em 25 de março de 1824 e foi, dentre todas, **a que durou mais tempo**, tendo sofrido considerável influência da francesa de 1814. Foi marcada por forte **centralismo administrativo e político**, tendo em vista a figura do **Poder Moderador**, constitucionalizado, e também por **unitarismo** e **absolutismo**.

Algumas importantes características do texto de 1824 podem ser destacadas:

■ **Governo:** monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Tratava-se de forma **unitária de Estado**, com nítida centralização político-administrativa.

■ **Território:** as antigas capitanias hereditárias foram transformadas em **províncias**, que, por sua vez, poderiam ser subdivididas. As províncias eram subordinadas ao Poder Central e tinham um “Presidente”, nomeado pelo

Imperador e que poderia ser removido a qualquer tempo (*ad nutum*) em nome do “bom serviço do Estado”.

■ **Dinastia imperante:** a do Senhor D. Pedro I, Imperador e Defensor Perpétuo do Brasil. Durante o Império tivemos, também, a dinastia de D. Pedro II.

■ **Religião Oficial do Império:** Católica Apostólica Romana. Todas as outras religiões eram permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, não podendo, contudo, ter qualquer manifestação externa de templo.

■ **Capital do Império brasileiro:** a cidade do **Rio de Janeiro** foi a capital do Império brasileiro de 1822 a 1889. Com o Ato Adicional n. 16, de 12.08.1834, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada em **Município Neutro** ou **Município da Corte**, entidade territorial para a sede da Monarquia. O Município Neutro apresentava importante característica: “o relacionamento direto com o poder central, ao invés da submissão ao poder da Província do Rio de Janeiro”.[88](#)

Essa desvinculação em relação à Província do Rio de Janeiro encontrava fundamento no art. 1.º, 2.ª parte, do referido Ato Adicional de 1834, que, em cumprimento à Lei n. 12, de 12.10.1832 (que facultava a alteração de alguns artigos da Constituição de 1824, dentre eles o art. 72), inovando, passou a permitir a autoridade da *Assembleia Legislativa da Província* também na cidade do Rio de Janeiro (a capital).

A cidade do Rio de Janeiro foi a *sede do poder federal* mesmo com a proclamação da República, nos termos do art. 10 do Decreto n. 1, de 15.11.1889. A primeira Constituição da República, de 1891, como se verá, transformou o antigo Município Neutro (cidade do Rio de Janeiro, desvinculada da Província do Rio de Janeiro) em Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União.

■ **Organização dos “Poderes”:** seguindo as ideias de Benjamin Constant,

não se adotou a separação tripartida de Montesquieu. Isso porque, além das funções legislativa, executiva e judiciária, estabeleceu-se a função **moderadora**. Nesse sentido, o art. 10 da Constituição do Império de 1824: “Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são **quatro**: o **Poder Legislativo**, o **Poder Moderador**, o **Poder Executivo**, e o **Poder Judicial**”.

■ **Poder Legislativo**: exercido pela **Assembleia Geral**, com a sanção do Imperador, que era composta de duas Câmaras — **Câmara de Deputados** e **Câmara de Senadores**, ou **Senado**. A Câmara dos Deputados era eletiva e temporária; a de Senadores, vitalícia, sendo os seus membros nomeados pelo Imperador dentre uma lista tríplice enviada pela Província.

■ **Eleições para o Legislativo**: indiretas.

■ **Sufrágio**: censitário, ou seja, baseava-se em determinadas condições econômico-financeiras de seus titulares (para votar e ser votado).

■ **Poder Executivo**: a função executiva era exercida pelo **Imperador**, Chefe do Poder Executivo, por intermédio de seus Ministros de Estado. Em um primeiro momento, para continuar no poder, os Ministros não dependiam da confiança do Parlamento.

Contudo, a partir da abdicação do trono por D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, na fase da Regência (que durou 9 anos, durante a menoridade de D. Pedro II, que contava com 5 anos de idade, tendo existido 4 Regências) e, em seguida, graças ao espírito moderado de D. Pedro II, o segundo Imperador do Brasil, que assumiu o trono aos 15 anos de idade, em 18 de julho de 1841, contribuiu para a paulatina instituição do **parlamentarismo monárquico no Brasil** durante o Segundo Reinado. [89](#)

O parlamentarismo se consolidou com a criação do cargo de *Presidente do Conselho de Ministros* pelo Decreto n. 523, de 20.07.1847, conforme o qual D. Pedro II escolhia o Presidente do Conselho e este, por sua vez, escolhia os demais Ministros, que deveriam ter a confiança dos Deputados e do Imperador,

sob pena de ser dissolvido (alguns chegam a denominá-lo um “parlamentarismo às avessas”, já que o Presidente do Conselho, que equivaleria ao Primeiro-Ministro da Inglaterra, era escolhido pelo Imperador e portanto a este subordinado, e não ao Parlamento).

■ **Poder Judiciário:** o denominado “Poder Judicial” era independente e composto de **juízes** e **jurados**. Os juízes aplicavam a lei; os jurados se pronunciavam sobre os fatos. Aos juízes de direito era assegurada a vitaliciedade (“os juízes de direito serão perpétuos”, só podendo perder o “lugar” por sentença), não se lhes assegurando, todavia, a inamovibilidade. O Imperador podia suspendê-los por queixas que lhe eram feitas. Para julgar as causas em segunda e última instância, nas Províncias do Império, foram criadas as **“Relações”**. Na Capital do Império foi estabelecido, como órgão de cúpula do Judiciário, o **Supremo Tribunal de Justiça**, composto de juízes togados, provenientes das “Relações” das Províncias e pelo critério da antiguidade.

■ **Poder Moderador:** sem dúvida, foi o “mecanismo” que serviu para assegurar a **estabilidade do trono** do Imperador durante o reinado no Brasil.

Afonso Arinos destaca que o criador da ideia de Poder Moderador, **Benjamin Constant**, sofreu forte influência de **Clermont Tonerre**.

Como relata, Benjamin Constant definia o Poder Moderador, por ele chamado de **“Poder Real”**, como *“la clef de toute organisation politique”*, frase esta consagrada no art. 98 da Constituição de 1824: **“o Poder Moderador é a chave de toda a organização Política**, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio e harmonia dos demais Poderes Políticos”[.90](#)

Muita discussão houve sobre o Poder Moderador, especialmente em razão da tradução do termo *“clef”*, ou seja, significando **“fecho”** para alguns ou **“chave”** para outros, este último como consta do art. 98 da Constituição de 1824.

Para os **liberais**, a melhor tradução seria **“fecho”**, no sentido de “apoio e

coordenação” em relação aos demais Poderes. Para os **conservadores**, a tradução mais adequada seria “**chave**”, dando a ideia de possibilidade de “abrir qualquer porta”, tendo em vista as constantes “intervenções” e “imposições” do Poder Moderador sobre os demais Poderes. [91](#)

Assim, na prática, parece que a tradução “chave” refletiu a constante interferência do Poder Moderador sobre os demais Poderes e o significado de Imperador, que recebeu os Títulos de “Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, tendo o tratamento de “Majestade Imperial” e sendo a sua pessoa inviolável e sagrada, não sujeita a responsabilidade alguma (irresponsabilidade total do Estado — “*the king can do no wrong*” — “o rei não erra”).

O **Imperador**, que exercia o **Poder Moderador**, no âmbito do **Legislativo**, nomeava os Senadores, convocava a Assembleia Geral extraordinariamente, sancionava e vetava proposições do Legislativo, dissolia a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra, que a substituíria. No âmbito do **Executivo**, nomeava e demitia livremente os Ministros de Estado. E, por fim, no âmbito do **Judiciário**, suspendia os Magistrados.

■ **Tentativa frustrada de se instalar o Estado Federativo durante o Império:** a Regência permanente, em nome do Imperador D. Pedro II, tendo em vista os poderes de reforma atribuídos pela Lei de 12.10.1832, nos termos do art. 1.º da Lei n. 16, de 12.08.1834 (**Ato Adicional**), criou as chamadas “Assembleias Legislativas Provinciais”, com considerável autonomia. Contudo, contrariamente ao interesse de determinados segmentos, não se conseguiu acabar com o Poder Moderador, nem com o absolutismo reinante, especialmente a partir do advento da Lei n. 105, de 12.05.1840, chamada “Lei de Interpretação”, que restabeleceu, fortemente, a ideia centralizadora e a figura do Poder Moderador.

■ **Insurreições populares:** durante o Império diversos movimentos populares eclodiram, seja por causas separatistas, seja por melhores condições sociais, destacando-se:

- a) Cabanagem (no Pará, 1835);
- b) Farroupilha (no Rio Grande do Sul, 1835);
- c) Sabinada (na Bahia, 1837);
- d) Balaiada (no Maranhão, 1838);
- e) Revolução Praieira (em Pernambuco, 1848).

■ **Constituição semirrígida:** nos termos do art. 178, conforme já estudamos, no tocante à classificação das Constituições quanto à *alterabilidade*, algumas normas, para serem alteradas, necessitavam de um procedimento mais árduo, mais solene e mais dificultoso; outras, entretanto, eram alteradas por um processo legislativo ordinário, sem nenhuma formalidade.

■ **Liberdades públicas:** por forte influência das Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789), configurando a ideia de **constitucionalismo liberal**,⁹² a Constituição de 1824 continha importante rol de Direitos Cíveis e Políticos. Sem dúvida influenciou as **declarações de direitos e garantias** das Constituições que se seguiram.

Não podemos, contudo, deixar de **execrar** a triste manutenção da escravidão, por força do regime que se baseava na “monocultura latifundiária e escravocrata”,⁹³ como mancha do regime até 13 de maio de 1888, data de sua abolição, quando da assinatura da **Lei Áurea** pela Princesa Isabel.⁹⁴

Muito embora não prevista a garantia do *habeas corpus*, cabe lembrar que o *Decreto n. 114, de 23.05.1821*, alvará de D. Pedro I, antes do texto, já proibía prisões arbitrárias. A Constituição de 1824, por si, tutelou a liberdade de locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e também vedou qualquer hipótese de prisão arbitrária.

Foi somente a partir do *Código Criminal* de 16.12.1830 (arts. 183 a 188) que se passou a estabelecer a garantia do *habeas corpus*, regra prevista, também, no *Código de Processo Criminal de Primeira Instância* (Lei n. 127, de 29.11.1832, arts. 340 a 345) e no art. 18 da *Lei n. 2.033, de 20.09.1871* (que assegurou a impetração também por estrangeiros).

A garantia do “HC”, como se verá, constitucionaliza-se somente no texto de 1891.

■ 2.6.2. Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo Provisório da República

A partir de 1860, começa-se a perceber um enfraquecimento da Monarquia. Em 1868, durante a *Guerra do Paraguai*, os militares passam a nutrir um forte sentimento de descontentamento com a Monarquia, sentimento esse que se intensificou em razão da candente “marginalização política” e redução do orçamento e efetivo militares.

O *Manifesto do Centro Liberal* (1869) e o *Manifesto Republicano* (1870) também contribuíram para abalar a Monarquia, atacando a vitaliciedade dos Senadores e o papel do Conselho de Estado.

Em 1874 tivemos fortes entraves entre a Igreja Católica e a Monarquia.

Nesse contexto, “desmoronando” as “colunas de apoio” ao Império, em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, afastando-se do poder D. Pedro II e toda a dinastia de Bragança, sem ter havido muita movimentação popular. Isso porque, como visto, tratava-se mais de um golpe de Estado militar e armado do que de qualquer movimento do povo. A República nascia, assim, sem legitimidade.

Consequentemente, as Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, passam a constituir os **Estados Unidos do Brasil**.

Entre 1889 e 1891 se instala no Brasil o **Governo Provisório** (Dec. n. 1, de 15.11.1889, redigido por Rui Barbosa), presidido por Deodoro da Fonseca e que tinha a importante missão de consolidar o novo regime e promulgar a primeira Constituição da República.

Nos termos do art. 10 do Decreto presidencial n. 1, de 15 de novembro de 1889, “o território do Município Neutro fica provisoriamente sob a administração imediata do Governo Provisório da República, e a **cidade do Rio de Janeiro** constituída, também provisoriamente, **sede do poder federal**”.

■ 2.6.3. Constituição de 1891

A Assembleia Constituinte foi eleita em 1890. Em 24 de fevereiro de 1891, a **primeira Constituição da República do Brasil** (a segunda do constitucionalismo pátrio) é promulgada, sofrendo pequena reforma em 1926. Vigorou até 1930.

A Constituição de 1891 teve por Relator o Senador **Rui Barbosa** e sofreu forte influência da Constituição norte-americana de 1787, consagrando o sistema de governo **presidencialista**, a forma de Estado **federal**, abandonando o unitarismo e a forma de governo **republicana** em substituição à monárquica.

■ **Forma de Governo e regime representativo:** nos termos do art. 1.º da Constituição de 1891, a Nação brasileira adotou, como forma de Governo, sob o **regime representativo**, a **República Federativa**, proclamada em 15 de novembro de 1889. Declarou, ainda, a **união perpétua e indissolúvel** das antigas Províncias, transformando-as em Estados Unidos do Brasil e vedando, assim, a possibilidade de secessão (qual seja, separação, segregação do pacto federativo).

■ **Distrito Federal — Capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro:** nos termos do art. 2.º da Constituição de 1891, o antigo Município Neutro (Rio de Janeiro, que era a sede do Poder Central do Império) foi transformado em **Distrito Federal**, continuando a ser a **Capital da União**, enquanto não cumprida a determinação contida no art. 3.º da Constituição de 1891, com a seguinte previsão: “fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela **estabelecer-se a futura Capital Federal**. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um **Estado**”.

Nesse sentido, o art. 1.º da primeira Lei Orgânica do DF, a Lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, manteve a natureza “municipal” da capital do País (o Distrito Federal), ao estabelecer: “o Distrito Federal compreende o território do

antigo Município Neutro, tem por sede a cidade do Rio de Janeiro e continua constituído em Município”.[95](#)

■ **Não há mais religião oficial:** o Brasil, nos termos do que já havia sido estabelecido pelo *Decreto n. 119-A, de 07.01.1890*, constitucionaliza-se como um país leigo, laico ou não confessional. Retiraram-se os efeitos civis do casamento religioso. Os cemitérios, que eram controlados pela Igreja, passaram a ser administrados pela autoridade municipal. Houve proibição do ensino religioso nas escolas públicas. Não se invocou, no preâmbulo da Constituição, a expressão “sob a proteção de Deus” para a sua promulgação.

Lembramos, por fim, que nos termos do art. 4.º do Decreto n. 119-A, de 07.01.1890, já havia sido extinto o **padroado** (direito que o Imperador tinha de intervir nas nomeações dos bispos, bem como nos cargos e benefícios eclesiásticos), com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas.

Como não havia mais religião oficial, naturalmente também, com o texto de 1891, ficou extinta a concessão ou negativa de **beneplácito régio** aos Decretos dos Concílios e Letras Apostólicas e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas (ou seja, a aprovação estatal dos aludidos documentos para a vigência interna, não existindo mais nos termos do art. 102, XIV, da Constituição de 1824).

Ainda, em igual sentido, o fato de o Estado ter-se separado da Igreja determinou a extinção do **recurso à Coroa** para atacar as decisões dos Tribunais Eclesiásticos.

■ **Organização dos “Poderes”:** o Poder Moderador foi extinto, adotando-se a teoria clássica de Montesquieu da tripartição de “Poderes”. Nesses termos, o art. 15 da Constituição de 1891 estabeleceu: “são órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si”.

■ **Poder Legislativo:** o Poder Legislativo federal era exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, sendo este composto por dois “ramos”, ou Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Fixava-se, assim, o **“bicameralismo federativo”**.

A Câmara dos Deputados era composta de representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante **sufrágio direto**, garantida a representação da minoria. Cada Deputado exercia mandato de **3 anos**.

Já o Senado Federal representava os Estados e o Distrito Federal, sendo eleitos 3 Senadores por Estado e 3 pelo Distrito Federal, eleitos do mesmo modo que os Deputados, para mandato de **9 anos**, renovando-se o Senado pelo terço trienalmente (ou seja, 1 a cada 3 anos, já que o mandato era de 9 anos e junto com as eleições para Deputados, que tinham mandato de 3 anos).

O Poder Legislativo também foi estabelecido em âmbito estadual. Alguns Estados, curiosamente, possuíam duas Casas, caracterizando-se, assim, a ideia de **bicameralismo estadual**, como podia ser percebido em São Paulo e Pernambuco, que tinham, além da Câmara dos Deputados (Estaduais), um Senado Estadual.

■ **Poder Executivo:** exercido pelo Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da Nação, era eleito junto com o Vice-Presidente por **sufrágio direto** da Nação, para mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito para um período subsequente.

Cabe alertar, contudo, nos termos do art. 1.º das Disposições Transitórias da Constituição de 1891, muito embora a previsão e conquista das **eleições diretas**, que a primeira eleição da República foi **indireta**, pelo Congresso Nacional, elegendo-se o Presidente *Marechal Deodoro da Fonseca* e o Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brasil *Marechal Floriano Peixoto*. [96](#)

O Presidente da República era auxiliado pelos Ministros de Estado, agentes de sua confiança que lhe subscreviam os atos e eram nomeados e demitidos livremente (*ad nutum*).

Interessante notar que alguns Estados designavam o seu Executivo local como “presidente”, enquanto outros, como “governador”. Assim, era possível perceber a figura de “presidentes estaduais” exercendo o Executivo local.

■ **Poder Judiciário:** o órgão máximo do Judiciário passou a chamar-se **Supremo Tribunal Federal**, composto de 15 “Juizes”. Estabeleceu-se a

hipótese dos crimes de responsabilidade. Houve expressa previsão da garantia da vitaliciedade para os Juízes Federais (art. 57) e para os membros do Supremo Tribunal Militar (art. 77, § 1.º). Para os Juízes Federais, houve expressa previsão da garantia da irredutibilidade de “vencimentos” (art. 57, § 1.º).

A **Justiça Federal** foi mantida na Constituição. Cabe mencionar que o **Decreto n. 848, de 11.10.1890**, por inspiração do modelo norte-americano da Constituição de 1787 (lembrando, ainda, o suíço de 1874 e o argentino, nos termos das Leis de 1882 e 1883), já havia criado a Justiça Federal no Brasil, exercida por um **Supremo Tribunal Federal** e por juízes inferiores intitulados **Juízes de Secção**.

■ **Constituição rígida:** nos termos do art. 90 previu-se um processo de alteração da Constituição mais árduo e mais solene do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Assim, perde sentido a anterior distinção que era feita no texto de 1824 entre norma material e formalmente constitucional. Estabeleceu-se, como cláusula pétrea, a **forma republicano-federativa** e a **igualdade da representação dos Estados no Senado**.

■ **Declaração de direitos:** a declaração de direitos foi aprimorada, abolindo-se a pena de galés (que já havia sido extinta pelo Dec. n. 774, de 20.09.1890),⁹⁷ a de banimento e a de morte, ressalvadas, neste último caso, as disposições da legislação militar em tempo de guerra.⁹⁸ Houve prevalência de proteção às clássicas liberdades privadas, civis e políticas, não se percebendo a previsão de direitos dos trabalhadores nos termos do que vai ser sentido no texto de 1934.

No tocante às **garantias constitucionais**, na Constituição de 1891 houve expressa previsão, pela primeira vez no constitucionalismo pátrio, do remédio constitucional do ***habeas corpus***.

Embora não prevista a garantia do *habeas corpus* no texto de 1824, cabe lembrar que o *Decreto n. 114, de 23.05.1821*, alvará de D. Pedro I, proibiu prisões arbitrárias; a Constituição de 1824, por si, tutelou a liberdade de

locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e vedou a prisão arbitrária; já a partir do *Código Criminal* de 16.12.1830 (arts. 183 a 188), passou-se a estabelecer a garantia do *habeas corpus*, regra prevista também no *Código de Processo Criminal de Primeira Instância*, Lei n. 127, de 29.11.1832 (arts. 340 a 345) e no art. 18 da Lei n. 2.033, de 20.09.1871 (que assegurou a impetração também por estrangeiros).

Em 03.09.1926 foi editada Emenda n. 1 à Constituição de 1891, limitando a chamada “teoria (ou doutrina) brasileira do *habeas corpus*” e restringindo o remédio constitucional do *habeas corpus* exclusivamente à **liberdade de locomoção**.

■ **Reforma de 03.09.1926:** houve centralização do poder, restringindo a autonomia dos Estados. Segundo Celso Bastos, a Reforma de 1926 foi “... marcada por uma conotação nitidamente racionalista, autoritária, introduzindo alterações no instituto da intervenção da União nos Estados, no Poder Legislativo, no processo legislativo, no fortalecimento do Executivo, nos direitos e garantias individuais e na Justiça Federal”. Isso tudo vai diminuir a sua “longevidade”, especialmente em razão do movimento armado de 1930, que pôs fim ao período chamado de “Primeira República”. [99](#)

■ 2.6.4. A Revolução de 1930 — segundo Governo Provisório da República

A chamada *República Velha* tem o seu fim com a *Revolução de 1930*, que instituiu o Governo Provisório nos termos do **Decreto n. 19.398, de 11.11.1930**, levando Getúlio Vargas ao poder. [100](#)

Barroso aponta dois aspectos mais graves a ensejar a ruína da República Velha: o **domínio das oligarquias** e a **fraude eleitoral institucionalizada**. Lembra, ainda, a **grave crise econômico-financeira de 1929** (“Grande Depressão”), uma **pequena burguesia** em ascensão, o **Tenentismo** (movimento contra o regime oligárquico que dirigia o Brasil) e o surgimento de uma **classe operária** descontente em razão do processo de industrialização estimulado pela

Primeira Guerra. [101](#)

Um outro episódio também contribuiu para a mobilização da oposição em prol da Revolução de 30, qual seja, o **assassinato de João Pessoa**, em 26 de julho de 1930, que deflagrou o **movimento militar** iniciado no Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, em 1930 uma Junta Militar transfere o poder para um **Governo Provisório**, que o exerceria até a promulgação do texto de 1934, motivada (a promulgação do texto democrático) por alguns elementos de pressão e contestação aos métodos arbitrários empregados, como o marcante papel da *Revolução Constitucionalista de São Paulo*, de 9 de julho de 1932. [102](#)

Nos termos do art. 1.º do Decreto n. 19.398/30, cabia ao Governo Provisório exercer, discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e atribuições não só do **Poder Executivo** como também do **Poder Legislativo**, até que, eleita a Assembleia Constituinte, se estabelecesse a reorganização constitucional do País.

O art. 2.º do aludido Decreto confirmava a dissolução do Congresso Nacional, das atuais Assembleias Legislativas dos Estados (sejam quais forem as suas denominações), Câmaras ou Assembleias Municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos existentes nos Estados, nos Municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e dissolvidos os que ainda o não tivessem sido de fato.

Foi nomeado um **interventor** para cada Estado, havendo controle, também, sobre os Municípios (art. 11).

A função legislativa, concentrada no Governo Provisório, como vimos, era exercida por **decretos** expedidos pelo Chefe do Governo e subscritos pelo Ministro respectivo (art. 17).

Como ponto positivo, em 1932 Getúlio Vargas decretou o importante **Código Eleitoral** (Dec. n. 21.076, de 24.02.1932), que instituiu a Justiça Eleitoral, trazendo, assim, garantias contra a política anterior, que “sepultou” a Primeira República, retirando a atribuição de proclamar os eleitos das assembleias políticas, e, ainda, adotou o **voto feminino** [103](#) e o **sufrágio universal, direto e secreto**.

Conforme visto, esse segundo Governo Provisório da República durou até o advento da Constituição de 1934, promulgada em 16.07.1934.

■ 2.6.5. Constituição de 1934

A crise econômica de 1929, consoante referido, bem como os diversos movimentos sociais por melhores condições de trabalho, sem dúvida, influenciaram a promulgação do texto de 1934, abalando, assim, os ideais do liberalismo econômico e da democracia liberal da Constituição de 1891.

Por isso é que a doutrina afirma, com tranquilidade, que o texto de 1934 sofreu forte influência da **Constituição de Weimar** da Alemanha de 1919, evidenciando, portanto, os **direitos humanos de 2.ª geração ou dimensão** e a perspectiva de um **Estado social de direito** (democracia social).

Há influência, também, do **fascismo**, já que o texto estabeleceu, o que se verá abaixo, além do voto direto para a escolha dos Deputados, a modalidade indireta, por intermédio da chamada **“representação classista”** do Parlamento.

Dentro do constitucionalismo pátrio, o texto de 1934 teve curtíssima duração, sendo abolido pelo golpe de 1937.

Foram mantidos alguns princípios fundamentais, como a República, a Federação, a tripartição de Poderes, o presidencialismo e o regime representativo, destacando-se as seguintes características:

■ **Forma de Governo e regime representativo:** nos termos do art. 1.º, a Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o regime **representativo**, a **República federativa** proclamada em 15 de novembro de 1889.

Os poderes da União foram consideravelmente aumentados, discriminando-se as rendas tributárias entre União, Estados e Municípios.

■ **Capital da República — Distrito Federal — tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro:** o Distrito Federal, administrado por um Prefeito, foi

mantido, com sede na cidade do Rio de Janeiro, como Capital da República. Nos termos do art. 4.º das disposições transitórias, havia a previsão de transferência da Capital da União para um ponto central do Brasil. O Presidente da República, logo que a Constituição entrasse em vigor, nomearia uma Comissão que, sob instruções do Governo, procederia a estudos de várias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos tais estudos, os resultados seriam apresentados à Câmara dos Deputados, que escolheria o local e tomaria, sem perda de tempo, as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o **Distrito Federal** passaria a constituir um **Estado**.

Nos termos do art. 5.º, XVI, a União editou a Lei n. 196, de 18.01.1936, a segunda Lei Orgânica do Distrito Federal, fixando amplo regime de autonomia para o DF, elevando-o à condição de **“supermunicípio”**, conforme o art. 1.º da referida lei, que o aproximava dos Estados, nos seguintes termos: “o atual Distrito Federal tem **autonomia equivalente à dos Estados**, ressalvadas as limitações decorrentes aos preceitos da Constituição Federal”.

■ **Mantida a inexistência de religião oficial:** o País continua leigo, laico ou não confessional, sendo inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre-exercício dos cultos religiosos, desde que não contravenham à ordem pública e aos bons costumes.

Amenizando o “sentimento” antirreligião do texto de 1891, na dicção do art. 146, passou-se a admitir o **casamento religioso com efeitos civis**, nos seguintes termos: “o casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo da oposição sejam observadas as disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registro Civil”. Ainda, segundo o art. 153, **facultou-se o ensino religioso nas escolas públicas**.

Finalmente, destaca-se a previsão de **“Deus”** no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica de Montesquieu da

tripartição de “Poderes” foi mantida. De acordo com o art. 3.º, são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si.

■ **Poder Legislativo:** era exercido pela Câmara dos Deputados com a **colaboração** do Senado Federal. Rompia-se, assim, com o princípio do **bicameralismo rígido** ou **paritário**, no qual as duas Casas exercem funções básicas idênticas. Estabelecia-se, por consequência, um **bicameralismo desigual**, também chamado pela doutrina de **unicameralismo imperfeito**, já que, como visto, o SF era mero colaborador da CD. [104](#)

O mandato dos Deputados era de 4 anos. A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do povo, eleitos mediante **sistema proporcional** e **sufrágio universal**, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei indicasse (**representação corporativa de influência fascista**). [105](#)

Já em relação ao **Senado Federal**, nos termos do art. 41, § 3.º, a competência legislativa se reduzia às matérias relacionadas à Federação, como a iniciativa das leis sobre a intervenção federal e, em geral, das que interessassem determinadamente a um ou mais Estados.

Conforme o art. 89, o Senado Federal era composto de dois representantes de cada Estado e o do Distrito Federal, eleitos mediante sufrágio universal, igual e direto, por **8 anos**, dentre brasileiros natos, alistados eleitores e maiores de 35 anos, sendo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal, no Senado, renovava-se pela metade, conjuntamente com a eleição da Câmara dos Deputados.

Por fim, dispunha o art. 88 que cabia ao Senado Federal, conforme os arts. 90, 91 e 92, a incumbência de promover a coordenação dos Poderes federais entre si, [106](#) manter a continuidade administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos de sua competência.

■ **Poder Executivo:** exercido pelo Presidente da República, eleito junto com o vice por sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos para mandato

de 4 anos, vedada a reeleição. O Presidente da República seria auxiliado pelos Ministros de Estado, que passaram a ter responsabilidade pessoal e solidária com o Presidente.

■ **Poder Judiciário:** foram estabelecidos como órgãos do Poder Judiciário: *a)* a Corte Suprema; *b)* os Juízes e Tribunais federais; *c)* os Juízes e Tribunais militares; *d)* os Juízes e Tribunais eleitorais, estabelecendo-se aos juízes as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de “vencimentos”. A Corte Suprema, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, compunha-se de 11 Ministros.

■ **Constituição rígida:** nos termos do art. 178, *caput*, “a Constituição poderá ser emendada, quando as alterações propostas não modificarem a estrutura política do Estado (arts. 1.º a 14, 17 a 21); a organização ou a competência dos poderes da soberania (Capítulos II, III e IV do Título I; o Capítulo V do Título I; o Título II; o Título III; e os arts. 175, 177, 181, este mesmo art. 178); e revista, no caso contrário”. O art. 178, § 5.º, fixou, como cláusula pétrea, a forma republicana federativa.

■ **Declaração de direitos:** nos termos do art. 108, constitucionaliza-se o **voto feminino**, com valor igual ao masculino, conforme já havia sido previsto no art. 2.º do Código Eleitoral de 1932 (Dec. n. 21.076, de 24.02.1932). Outra garantia foi a constitucionalização do **voto secreto** (também chamado de “**voto australiano**” por ter surgido, pela primeira vez, na Austrália, em 1856), que já havia sido assegurada pelo Código Eleitoral de 1932.

Vários direitos clássicos são mantidos. Inovando, em razão do caráter social da Constituição, são destacados novos títulos, como o da ordem econômica e social (Título IV), da família, educação e cultura (Título V) e da segurança nacional (Título VI).

Prestigiam-se, assim, a legislação trabalhista e a representação classista.

Dentre as novidades dos remédios constitucionais, destacamos a previsão, pela primeira vez, do **mandado de segurança** (art. 113, n. 33) e da **ação**

popular (art. 113, n. 38). [107](#)

■ 2.6.6. Constituição de 1937

Getúlio Vargas foi eleito e empossado para governar de 1934 até 1938. Contudo, durante esse período, um forte antagonismo foi percebido entre a **direita fascista** de um lado (em especial a *Ação Integralista Brasileira — AIB*), defendendo um Estado **autoritário**, e o **movimento de esquerda** de outro, destacando ideais socialistas, comunistas e sindicais (em especial a formação, em 1935, da *Aliança Nacional Libertadora — ANL*).

■ direita fascista		■ movimento de esquerda
■ Estado autoritário	X	■ ideais socialistas, comunistas e sindicais
■ Ação Integralista Brasileira — AIB		■ Aliança Nacional Libertadora — ANL

Em 11 de julho de 1935, o Governo fechou a Aliança Nacional Libertadora — ANL, considerando-a ilegal com base na “Lei de Segurança Nacional”, cujo estopim da crise foi o manifesto lançado por Luís Carlos Prestes.

Em razão da **Intentona Comunista** (novembro de 1935 — Natal, Recife e Rio de Janeiro — insurreição político-militar que contava com o apoio do Partido Comunista Brasileiro e de ex-tenentes — agora militares comunistas —, e que tinha o objetivo de derrubar Getúlio Vargas e instalar o socialismo no Brasil), o **estado de sítio** foi decretado pelo Governo e se deflagrou um forte movimento de repressão ao comunismo, inclusive com o apoio da famigerada “Polícia Especial”.

Getúlio Vargas e o Governo tiveram o apoio do Congresso Nacional, que decretou o **“estado de guerra”**.

Em 30 de setembro de 1937, os jornais noticiaram que o Estado-Maior do Exército havia descoberto um plano comunista para a tomada do Poder (**“Plano Cohen”**). Este foi o “estopim” para que o Governo decretasse o golpe como suposta “salvação” contra o comunismo que parecia “assolar” o País.

Tendo o apoio dos Generais Góis Monteiro (Chefe do Estado-Maior do Exército) e Eurico Gaspar Dutra (Ministro da Guerra), bem como diante de uma nova decretação de “estado de guerra” pelo Congresso Nacional, em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas dá o golpe ditatorial, centralizando o poder e fechando o Congresso Nacional.

Era o início do que **Vargas** intitulou de **“nascença da nova era”**, outorgando-se a Constituição de 1937, influenciada por ideais **autoritários** e **fascistas**, instalando a **ditadura** (“Estado Novo”), que só teria fim com a redemocratização pelo texto de 1945, e se declarando, em todo o País, o **estado de emergência**.

A **Carta de 1937**, elaborada por **Francisco Campos**, foi apelidada de **“Polaca”** em razão da influência sofrida pela Constituição polonesa fascista de 1935, imposta pelo *Marechal Josef Pilsudski*. Deveria ter sido submetida a plebiscito nacional, nos termos de seu art. 187, o que nunca aconteceu.

Além de fechar o Parlamento, o Governo manteve amplo domínio do Judiciário. A Federação foi abalada pela nomeação dos interventores. Os direitos fundamentais foram enfraquecidos, sobretudo em razão da atividade desenvolvida pela “Polícia Especial” e pelo “DIP — Departamento de Imprensa e Propaganda”. Para piorar, pelo Decreto-lei n. 37, de 02.12.1937, os partidos políticos foram dissolvidos.

Apesar do regime extremamente autoritário, na medida em que o Estado, centralizador, atuava diretamente na economia, não se pode negar o seu importante crescimento nesse setor.

Buscando atrair o apoio popular, a política desenvolvida foi denominada “populista”, consolidando-se as Leis do Trabalho (CLT) e importantes direitos sociais, como o salário mínimo.

Algumas características, então, podem ser esquematizadas:

■ **Forma de Governo:** nos termos do art. 1.º, o Brasil é uma **República**. O poder político emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, de sua honra, de sua independência e de sua prosperidade.

■ **Forma de Estado:** o Brasil é um Estado **federal**, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.

Na prática, contudo, as autonomias estaduais foram reduzidas, e podemos dizer que o regime federativo foi simplesmente “**nominal**”, havendo constante, senão até permanente, assunção dos governos estaduais por interventores federais. Por sua vez, os vereadores e prefeitos eram nomeados pelos interventores de cada Estado.

■ **Distrito Federal — Capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro:** nos termos do art. 7.º, o Distrito Federal, que continuou como capital federal, como sede do Governo da República, era administrado pela União. Explicitando, de acordo com o art. 30, o Distrito Federal era administrado por Prefeito nomeado pelo Presidente da República, com a aprovação do Conselho Federal, e demissível *ad nutum*, cabendo as funções deliberativas ao Conselho Federal.

■ **Não há mais religião oficial:** continuava o Brasil como país leigo, laico ou não confessional, não havendo, contudo, a invocação da “proteção de Deus” no preâmbulo da Constituição.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi *formalmente* mantida. Entretanto, na prática, tendo em vista o forte traço autoritário do regime, o Legislativo e o Judiciário foram “esvaziados”.

■ **Poder Legislativo:** de acordo com o art. 38, o Poder Legislativo seria exercido pelo **Parlamento Nacional** com a colaboração do **Conselho da Economia Nacional** e do **Presidente da República**.

Havia a previsão de composição do Parlamento Nacional por duas Câmaras: a **Câmara dos Deputados** e o **Conselho Federal**. Como se percebe, o **Senado Federal deixou de existir durante o Estado Novo**.

A Câmara dos Deputados seria composta de representantes do povo, eleitos mediante **sufrágio indireto** para mandato de 4 anos. Já o Conselho Federal seria composto de representantes dos Estados e 10 membros nomeados pelo Presidente da República. A duração do mandato era de 6 anos.

Cabe alertar, no entanto, que, segundo o art. 178, foram **dissolvidos** a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais, marcando-se eleições futuras para o novo Parlamento. Enquanto não se reunisse o Parlamento nacional, o Presidente da República tinha o poder de expedir **decretos-leis** sobre todas as matérias da competência legislativa da União. Na prática, o Legislativo nunca chegou a se instalar.

■ **Poder Executivo:** na dicção do art. 73, o Presidente da República, **autoridade suprema do Estado**, coordenava a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirigia a política interna e externa, promovia ou orientava a política legislativa de interesse nacional, e superintendia a administração do País.

A **eleição indireta** foi estabelecida para a escolha do Presidente da República, que cumpriria mandato de 6 anos.

■ **Poder Judiciário:** eram órgãos do Poder Judiciário (art. 90): *a)* o Supremo Tribunal Federal; *b)* os Juízes e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; *c)* os Juízes e Tribunais militares. A Justiça Eleitoral foi extinta e, conforme já visto, também os partidos políticos.

O Judiciário, contudo, foi **“esvaziado”**. Como exemplo, nos termos do art. 96, parágrafo único, no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, fosse necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia ele submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmasse por 2/3 dos votos

em cada uma das Câmaras, **ficaria sem efeito a decisão do Tribunal**.

Outra demonstração de “força” do poder central está no art. 170, ao estabelecer que, durante o estado de emergência ou o estado de guerra, os atos praticados em virtude deles não poderiam ser conhecidos por qualquer Juiz ou Tribunal.

■ **Declaração de direitos:** não houve previsão do mandado de segurança nem da ação popular. Não se tratou dos princípios da irretroatividade das leis e da reserva legal. O direito de manifestação do pensamento foi restringido, pois previa o art. 122, n. 15, “a”, que, com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a **censura prévia** da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão podia ser exercida, facultando-se à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação.

Nenhum jornal poderia recusar a inserção de comunicados do Governo, nas dimensões taxadas em lei (art. 122, n. 15, “b”).

Segundo o art. 122, n. 13 (e em sua redação determinada pela Lei Constitucional n. 1, de 16.05.1938), além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a **pena de morte** poderia ser aplicada para **crimes políticos** e nas hipóteses de **homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade**.

Nos termos do art. 177, que vigorou durante todo o Estado Novo, embora o seu prazo inicial tenha sido limitado a 60 dias (tendo em vista a faculdade trazida pela Lei Constitucional n. 2, de 16.05.1938), o Governo poderia **aposentar** ou **reformular**, de acordo com a legislação em vigor, os funcionários civis e militares cujo afastamento se impusesse a juízo exclusivo do “Governo”, no interesse do serviço público ou por conveniência do regime.

Foi declarado o **estado de emergência** (art. 186), que, suspendendo direitos e garantias individuais, só veio a ser revogado pela Lei n. 16, de 30.11.1945.

A **greve** e o **lock-out** foram **proibidos**, tendo sido declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional (art. 139).

O art. 173, na sua redação determinada pela Lei Constitucional n. 7, de 30.09.1942, estabeleceu a possibilidade de declarar o “**estado de guerra**”, com restrição a direitos fundamentais e, ainda, o julgamento de crimes cometidos contra a **estrutura das instituições**, a **segurança do Estado** e dos **cidadãos pela Justiça Militar** ou pelo **Tribunal de Segurança Nacional**. Este último só veio a ser extinto pela Lei Constitucional n. 14, de 17.09.1945.

A **tortura** foi utilizada como instrumento de repressão, situação essa simbolizada pela entrega de Olga Benário, mulher de Luís Carlos Prestes, líder comunista no Brasil, que viria a ser assassinada em campo de concentração nazista na Alemanha.

■ **Nacionalização formal da economia e conquista de direitos e vantagens trabalhistas:** muito embora essa “triste” realidade ditatorial, durante o período houve inegável “nacionalização formal da economia”, bem como “controle sobre certas áreas estratégicas de produção, como mineração, aço e petróleo”, configurando, assim, importante “expansão capitalista”. [108](#)

Podemos citar as seguintes estatais criadas durante o período: Companhia Vale do Rio Doce (1942), Companhia Nacional de Álcalis (1943), Fábrica Nacional de Motores (1943) e Companhia Hidroelétrica do São Francisco (1945).

Também tivemos avanços no campo trabalhista. Contudo, como anota Barroso, nesse contexto, “... a Constituição não desempenhou papel algum, substituída pelo mando personalista, intuitivo, autoritário. Governo de fato, de suporte policial e militar, sem submissão sequer formal à Lei maior, que não teve vigência efetiva, salvo quanto aos dispositivos que outorgavam ao chefe do Executivo poderes excepcionais”. [109](#)

■ 2.6.7. Constituição de 1946

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Governo brasileiro declarou ofensiva contra os países do “**Eixo**” (destacando-se como principais potências a

Alemanha, a Itália e o Japão), entrando no confronto ao lado dos “**Aliados**” (destacando-se como principais potências a China, a França, a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos). Como marco histórico, em 1943, ressaltamos a criação da **FEB — Força Expedicionária Brasileira**.

A entrada na Guerra fez com que Vargas perdesse importante apoio, situação essa materializada na publicação, em 24 de outubro de 1943, do **Manifesto dos Mineiros**, carta assinada por intelectuais que apontava a contradição entre a política interna e a externa.

Isso porque, ao aderir à Guerra ao lado dos “Aliados”, buscando enfrentar as ditaduras nazifascistas de Mussolini e Hitler (países do “Eixo”), parecia natural que o fascismo fosse “varrido” da realidade brasileira, não se sustentando, internamente, a contradição de manter um Estado arbitrário com base em uma Constituição inspirada no modelo fascista e externamente lutar contra esse regime.

Outros documentos, na mesma linha do *Manifesto dos Mineiros*, foram assinados. Essa crise política forçou Vargas a assinar o **Ato Adicional** em 1945 (Lei Constitucional n. 9, de 28.02.1945), convocando eleições presidenciais e marcando a derrocada final do “Estado Novo”.

Durante a campanha eleitoral, surge o movimento chamado “**queremismo**”, que significava “Queremos Getúlio”, e tudo levava a crer, especialmente com o apoio do partido comunista, agora legalizado, que Getúlio iria continuar e, eventualmente, até dar um novo golpe.

Em 29 de outubro de 1945, Vargas tentou substituir o chefe de Polícia do Distrito Federal por seu irmão, Benjamin Vargas. Além disso, nomeou João Alberto para Prefeito do Rio de Janeiro, fatos que precipitariam o fim do Estado Novo, já que davam a entender a vontade de Vargas continuar no Poder.

Esses fatos culminaram com a “expulsão” de **Vargas** do poder pelos Generais Gaspar Dutra e Góis Monteiro, sendo, assim, **deposto pelas Forças Armadas**.

Convocado pelas Forças Armadas, o Executivo passou a ser exercido pelo então **Presidente do STF**, *Ministro José Linhares*, que governou de 29.10.1945 a 31.01.1946, até assumir, eleito pelo **voto direto** e com mais de 55% de

aprovação dos eleitores, o *General Gaspar Dutra* como o novo Presidente da República.

José Linhares praticou importantes atos, como: **a)** a revogação do art. 177 (que permitia a aposentadoria ou reforma compulsórias, a exclusivo juízo do Governo, de funcionários civis e militares); **b)** a extinção do *Tribunal de Segurança Nacional*; **c)** a revogação do *estado de emergência*; **d)** a extinção do *Conselho de Economia Nacional*; **e)** a abolição da regra que permitia o esvaziamento da efetividade das decisões do STF em controle de constitucionalidade (art. 96, parágrafo único).

A Lei Constitucional n. 13, de 12.11.1945, atribuiu **poderes constituintes** ao Parlamento que seria eleito em 02.12.1945 para a elaboração da nova Constituição do Brasil.

A Assembleia Constituinte foi instalada em 1.º.02.1946, vindo o texto a ser **promulgado** em 18.09.1946. Tratava-se da **redemocratização do País**, repudiando-se o Estado totalitário que vigia desde 1930.

O texto inspirou-se nas ideias liberais da Constituição de 1891 e nas ideias sociais da de 1934. Na ordem econômica, procurou harmonizar o princípio da livre-iniciativa com o da justiça social.

■ **Forma de Governo Republicana e Forma de Estado Federativa:** nos termos do art. 1.º, os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República. Prestigiam o municipalismo.

■ **Capital da União:** o Distrito Federal continuou como a Capital da União e na área geográfica do antigo Município Neutro (a cidade do Rio de Janeiro).

Cabe lembrar, contudo, a previsão do art. 4.º do ADCT: a Capital da União será **transferida** para o planalto central do País. Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em 60 dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital. O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União. Findos os

trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança da Capital. Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o **Estado da Guanabara**.

Como se sabe, cumprindo o “Plano de Metas” (“50 anos em 5”), *Juscelino Kubitschek*, além de suas importantes realizações econômicas, implementa a construção de **Brasília**, inaugurada em **21 de abril de 1960**. Nessa data, conforme mandamento estabelecido na Constituição, o então Distrito Federal é transformado no **Estado da Guanabara**, com os mesmos limites geográficos, tendo por capital e sede do Governo a cidade do Rio de Janeiro (cf. **Lei n. 3.752/60**, conhecida como *Lei San Tiago Dantas*, deputado federal encarregado de elaborar o projeto de criação do novo Estado, que ditou normas para a convocação da Assembleia Constituinte).

A título de curiosidade, o Estado da Guanabara não foi dividido em municípios, decisão essa que encontrou apoio popular no **plebiscito** realizado em 21 de abril de 1963, além de ter curta duração (1960-1975). Por força do art. 8.º, da **LC n. 20/74**, a partir de 15.03.1975, os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara passaram a constituir um único Estado (fusão), sob a denominação de **Estado do Rio de Janeiro**, sendo a cidade do Rio de Janeiro a Capital.

■ **Inexistência de religião oficial:** continuou o País leigo, muito embora a expressa menção a “Deus” no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi restabelecida.

■ **Poder Legislativo:** consoante previa o art. 37, o Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, reaparecendo o bicameralismo igual.

A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do povo, eleitos, segundo o sistema de representação proporcional, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Territórios, para mandato de 4 anos.

O Senado Federal, por sua vez, compunha-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário e para mandato de 8 anos. Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegia 3 Senadores, renovando-se a representação de cada Estado e a do Distrito Federal de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3.

Nos termos do art. 61, as funções de Presidente do Senado Federal eram exercidas pelo **Vice-Presidente da República**.

Nos termos do art. 141, § 13, constitucionalizaram-se os Partidos Políticos, sendo vedada a organização, o registro ou o seu funcionamento nas hipóteses em que o programa ou a ação contrariassem o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.

■ **Poder Executivo:** retomando a normalidade democrática, o Presidente da República deveria ser eleito de **forma direta** para mandato de **5 anos**, junto com o vice, que, como visto, acumulava a função de Presidente do Senado Federal.

■ **Poder Judiciário:** foi retomada a situação de normalidade.

O Poder Judiciário era exercido pelos seguintes órgãos: *a)* Supremo Tribunal Federal; *b)* Tribunal Federal de Recursos; *c)* Juízes e Tribunais militares; *d)* Juízes e Tribunais eleitorais; *e)* Juízes e Tribunais do trabalho.

■ **Declaração de direitos:** o mandado de segurança e a ação popular foram restabelecidos no texto constitucional.

O art. 141, § 4.º, consagrou o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ao estabelecer que “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito *individual*”.

Conforme referido, passa-se, pela primeira vez, a prever regras para os partidos políticos (art. 141, § 13).

Pelo art. 141, § 31, **vedou-se**, caracterizando o cunho humanitário, a **pena de morte** (salvo as disposições da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro), a de **banimento**, a de **confisco** e a de **caráter perpétuo**.

Nos termos do art. 158, foi **reconhecido o direito de greve**. As várias garantias dos trabalhadores já conquistadas durante o “Estado Novo” foram mantidas, marcando importante “degrau” na evolução social do País.

■ **Instituição do parlamentarismo:** perdendo o apoio político, tanto do centro como da direita, o Presidente Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, encaminhando carta ao Congresso Nacional pela qual afirmava que teria sido pressionado por “forças ocultas terríveis”.

O Vice-Presidente João Goulart (Jango) estava na China e, assim, as Forças Armadas tentaram impedir o seu retorno, tendo em vista o receio com suas ligações comunistas.

Não aceitando o inconstitucional afastamento de Jango, o Congresso Nacional, tentando ser conservador, aprovou, em 02.09.1961, o regime parlamentarista (que também já havia sido experimentado durante o Império).

A grande novidade era a dualidade do Executivo, exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a estes a responsabilidade política do Governo. Conforme o art. 3.º, I, da EC n. 4/61, o Presidente da República nomeava o Primeiro-Ministro, que, por sua vez, escolhia os demais Ministros a serem nomeados pelo Presidente da República.

Feito o referendo, em 06.01.1963, o povo determinou o retorno imediato ao presidencialismo, conforme já estudado no *item 17.1.2.1*, que remanesceria até a Revolução Militar de 1964.

■ 2.6.8. Golpe Militar de 1964

Jango foi derrubado por um movimento militar que eclodiu em 31.03.1964, tendo sido acusado de estar a serviço do “comunismo internacional”. Instalava-se, assim, uma nova “ordem revolucionária” no País.

O General *Costa e Silva*, o Brigadeiro *Francisco Correia de Melo* e o Almirante *Augusto Rademaker*, militares vitoriosos, constituíram o chamado *Supremo Comando da Revolução* e, em 09.04.1964, baixaram o Ato

Institucional n. 1, de autoria de Francisco Campos (o mesmo que elaborou a Carta de 1937), com muitas restrições à democracia: **a)** o Comando da Revolução poderia decretar o estado de sítio (art. 6.º); **b)** conferia-se o poder de aposentar civis ou militares (art. 7.º); **c)** sem as limitações previstas na Constituição estabelecia-se a possibilidade de suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluía a apreciação judicial desses atos etc. (art. 10).

O AI 2/65, após ter estabelecido **eleições indiretas** para Presidente e Vice-Presidente da República, foi seguido pelo de n. 3, que também as estabeleceu em âmbito estadual.

O Congresso Nacional foi fechado em 1966, sendo reaberto, posteriormente, nos termos do AI 4/66 para aprovar a Constituição de 1967.

Alguns autores entendem que o texto de 1967 teria sido “promulgado”, já que votado nos termos do art. 1.º, § 1.º, do AI 4/66. Contudo, em razão do “autoritarismo” implantado pelo *Comando Militar da Revolução*, não possuindo o Congresso Nacional liberdade para alterar substancialmente o novo Estado que se instaurava, preferimos dizer que o texto de 1967 foi **outorgado** unilateralmente (apesar de formalmente votado, aprovado e “promulgado”) pelo regime ditatorial militar implantado.

Em conclusão, pode-se afirmar que a Constituição de 1946 foi suplantada pelo Golpe Militar de 1964. Embora continuasse existindo formalmente, o País passou a ser governado pelos Atos Institucionais e Complementares, [110](#) com o objetivo de consolidar a “Revolução Vitoriosa”, que buscava combater e “drenar o bolsão comunista” que assolava o Brasil.

■ 2.6.9. Constituição de 1967

Na mesma linha da Carta de 1937, a de 1967 concentrou, bruscamente, o poder no âmbito federal, esvaziando os Estados e Municípios e conferindo amplos poderes ao Presidente da República. Houve forte preocupação com a **segurança nacional**. Algumas características podem ser destacadas:

■ **Forma de Governo:** República.

■ **Forma de Estado:** muito embora o art. 1.º estabelecesse ser o Brasil uma República **Federativa**, constituída, sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, na prática, o que se percebeu foi um **duro “golpe” no federalismo**, mais se aproximando de um Estado unitário centralizado do que federativo.

■ **Capital da União:** nos termos do art. 2.º, o **Distrito Federal** permaneceu como a Capital da União, lembrando que os Poderes da República já haviam sido transferidos para Brasília, no **Planalto Central do País**, inaugurada em 21 de abril de 1960.

■ **Inexistência de religião oficial:** continuou o Brasil a ser um país leigo, embora houvesse a expressa menção a “Deus” no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi formalmente mantida. Anota Celso Bastos, acertadamente, que, apesar da previsão da tripartição de Poderes, “... no fundo existia um só, que era o Executivo, visto que a situação reinante tornava por demais mesquinhas as competências tanto do Legislativo quanto do Judiciário...”. [111](#)

■ **Poder Legislativo:** a teor do art. 29, o Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, que se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados era formada por representantes do povo, eleitos por voto direto e secreto, em cada Estado e Território e para mandato de 4 anos. O Senado Federal compunha-se de representantes dos Estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário. Cada Estado elegia 3 Senadores, com mandato de 8 anos, renovando-se a representação de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3.

Na prática, contudo, como visto, o Legislativo teve a sua competência diminuída.

Além disso fortaleceu-se a representação dos Deputados nos Estados menores: “o número de Deputados será fixado em lei, em proporção que não exceda de um para cada trezentos mil habitantes, até vinte e cinco Deputados, e, além desse limite, um para cada milhão de habitantes” (art. 41, § 2.º).

■ **Poder Executivo:** fortalecido, era eleito para mandato de 4 anos, de maneira **indireta** por sufrágio do Colégio Eleitoral, composto pelos membros do Congresso Nacional e de Delegados indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados, em sessão pública e mediante votação nominal.

O Presidente da República legislava por **decretos-leis**, que poderiam ser editados em casos de *urgência* ou de *interesse público relevante*, e desde que não resultassem em aumento de despesa sobre as seguintes matérias: *a)* segurança nacional; *b)* finanças públicas.

O art. 58, parágrafo único, previa a criticada **aprovação por decurso de prazo** do decreto-lei, já que, publicado o texto, que tinha vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovava ou o rejeitava, dentro de 60 dias, não podendo emendá-lo. Se, porém, nesse prazo não houvesse deliberação, o texto seria tido como aprovado.

Nos termos do art. 60, estrategicamente, estabeleceu-se a **iniciativa exclusiva** do Presidente da República para certas matérias, ou seja, só ele poderia deflagrar (dar início) o processo legislativo.

■ **Poder Judiciário:** o Poder Judiciário da União era exercido pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal; Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes do Trabalho. Havia previsão da Justiça Estadual. Em razão do centralismo, o Judiciário também teve a sua competência diminuída.

■ **Declaração de direitos:** havia exagerada possibilidade de suspensão de direitos políticos por 10 anos (art. 151).

Houve a previsão de se tornar perdida a propriedade para fins de reforma agrária, mediante o pagamento de indenização com títulos da dívida pública.

Os direitos dos trabalhadores foram definidos com maior eficácia.

■ **Sistema tributário:** conforme anota Celso Bastos, “... o Sistema Tributário Nacional, que há pouco sofrera uma modificação, por meio da Emenda Constitucional n. 18 à Constituição de 1946, foi em princípio mantido. Contudo, a discriminação de rendas, ampliando a técnica do **federalismo cooperativo**, acabou por permitir uma série de participações de uma entidade na receita da outra, com acentuada centralização. Quanto à matéria orçamentária aparecem o orçamento-programa, os programas plurianuais de investimento, além da própria atualização do sistema orçamentário”.[112](#)

■ **AI-5, de 13.12.1968:** o AI-5, o famigerado e mais violento ato baixado pela ditadura, perduraria até a sua revogação pela EC n. 11, de 17.10.1978, fixando as seguintes “atrocidades”,[113](#) nos termos de sua ementa:

- a) formalmente, foram mantidas a Constituição de 24.01.1967 e as Constituições Estaduais, com as modificações constantes do AI-5;
- b) o Presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando a funcionar quando convocados seus membros pelo Presidente da República;
- c) o Presidente da República, no interesse nacional, poderia decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição;
- d) os direitos políticos de quaisquer cidadãos poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos e cassados os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais;
- e) ficaram suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo;
- f) o Presidente da República, em quaisquer dos casos previstos na

Constituição, poderia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo;

g) o Presidente da República poderia, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tivessem enriquecido ilicitamente, no exercício do cargo ou função;

h) suspendeu-se a garantia de *habeas corpus*, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular (art. 10 do AI-5);

i) finalmente, a triste previsão do art. 11 do AI-5: “excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos”.

No mesmo dia em que o AI-5 foi baixado por *Costa e Silva*, o **Congresso Nacional** foi **fechado**, nos termos do Ato Complementar n. 38, de 13.12.1968, situação essa que perdurou por mais de 10 meses.

■ 2.6.10. “Constituição” de 1969 — EC n. 1, de 17.10.1969

A EC n. 1/69 não foi subscrita pelo Presidente da República Costa e Silva (15.03.1967 a 31.08.1969), impossibilitado de governar por sérios problemas de saúde, nem, “estranhamente”, pelo Vice-Presidente Pedro Aleixo, um civil.

Com base no AI 12, de 31.08.1969, consagrou-se no Brasil um governo de **“Juntas Militares”**, uma vez que referido ato permitia que, enquanto Costa e Silva estivesse afastado por motivos de saúde, governassem os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Nesse sentido, e com “suposto” fundamento, é que a EC n. 1/69 foi baixada pelos Militares, já que o Congresso Nacional estava fechado. [114](#)

Sem dúvida, dado o seu caráter revolucionário, podemos considerar a EC n. 1/69 como a manifestação de um novo **poder constituinte originário**, outorgando uma nova Carta, que “constitucionalizava” a utilização dos Atos Institucionais. Nos termos de seu art. 182, manteve em vigor o AI-5 e todos os

demaís atos baixados. O mandato do Presidente foi aumentado para **5 anos**, continuando a eleição a ser **indireta**.

Durante o governo do General Emílio Médici (30.10.1969 a 15.03.1974), o País experimentou o denominado **“milagre econômico”**,¹¹⁵ que trouxe uma pequena ilusão de pontos positivos ao novo regime (extremamente duro e autoritário, deixe-se bem claro).

Logo em seguida, do ponto de vista econômico, o governo de Ernesto Geisel (15.03.1974 a 15.03.1979) foi marcado por **forte inflação** e **grave crise econômica** (sobretudo em razão do petróleo). O governo perdia força e temia a oposição, especialmente após a derrota nas eleições legislativas de novembro de 1974.

Nesse contexto, o governo baixou a **Lei Falcão** (Lei n. 6.339, de 1.º.07.1976, assim apelidada já que *Armando Ribeiro Falcão* era o Ministro da Justiça que referendava o ato), reduzindo a propaganda política e, portanto, prejudicando a oposição.

O Presidente Geisel baixou, também, o **Pacote de Abril de 1977**, dissolvendo o Congresso Nacional e editando 14 emendas e 6 decretos, destacando-se as seguintes medidas:

- a)** redução do *quorum* para aprovação de EC de 2/3 para maioria absoluta, **flexibilizando**, assim, a teórica rigidez constitucional;
- b)** estabelecimento da **avocatória**, conforme o previsto no art. 119, I, “o”, da EC n. 1/69, introduzido pela EC n. 7/77: “as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais, cuja avocação deferir a pedido do Procurador-Geral da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de decisão proferida e para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido”;¹¹⁶
- c)** um terço dos Senadores passou a ser “eleito” pelas Assembleias Legislativas, ou melhor, pelo Colégio Eleitoral estadual, nos termos do art. 41, § 2.º, na redação conferida pela EC n. 8/77. Como a ARENA (partido

governamental) detinha a maioria (com a exceção do Estado da Guanabara, no qual saiu vitorioso o MDB), na prática se presenciou uma esquisita “nomeação” dos Senadores (já que a ARENA detinha a maioria nos Estados), que, ironicamente, foram apelidados pela população de **Senadores biônicos**;

d) aumento do mandato do Presidente da República de 5 (EC n. 1/69) para **6 anos** (EC n. 8/77);

e) manutenção da regra da **proporcionalidade** para a eleição de Deputados o que beneficiava os Estados menores, nos quais, supostamente, o governo teria maior controle.

Em seguida, tivemos o **pacote de junho de 1978**, destacando-se:

a) a revogação total ao AI-5;

b) a suspensão das medidas que, com base no AI-5, cassaram direitos políticos;

c) a previsão de impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional pelo Presidente da República, eliminando, assim, alguns poderes presidenciais.

Era o início de um processo de redemocratização [117](#) que viria a ganhar força durante a presidência de João Figueiredo (15.03.1979 a 15.03.1985 — mandato de **6 anos**, conforme a EC n. 8/77), que por sua vez teve a missão de pôr fim ao governo militar.

■ **Lei da Anistia (Lei n. 6.683, de 28.08.1979)**: foi concedida a anistia para todos que, no período compreendido entre 02.09.1961 e 15.08.1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. Nesse particular, cabe destacar que o STF, em 29.04.2010, no julgamento da **ADPF 153**, rejeitou o pedido de revisão da referida “Lei da Anistia” (cf. discussão sobre este assunto e a punição do Brasil pela *Corte*

Interamericana dos Direitos Humanos no item 21.4.2).

■ **Reforma Partidária — Lei n. 6.767, de 20.12.1979:** ao modificar dispositivos da Lei n. 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), a teor do art. 152 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional n. 11/78, trouxe a importante novidade de pôr fim ao bipartidarismo (ARENA v. MDB), regulamentando o **pluripartidarismo partidário**. A ARENA passou a chamar-se PDS (Partido Democrático Social), e do MDB estabeleceram-se cinco partidos novos: PMDB, PP, PT, PDT e PTB.

■ **EC n. 15, de 21.11.1980 — eleições diretas em âmbito estadual:** em 1982, tivemos importante marco histórico, qual seja, a **eleição direta** para Governadores de Estado em razão da alteração trazida pela EC n. 15/80. O PDS ganhou em 12 Estados, o PMDB, em 10, e o PDT, em 1.

■ **“Diretas Já”:** em 18.04.1983, o então Deputado Federal Dante de Oliveira apresentou a PEC n. 5/83, propondo **eleição direta** para Presidente e Vice-Presidente da República. A PEC ganhou o apoio popular e se transformou no importante movimento que ficou conhecido como “Diretas Já”. Apesar da pressão da sociedade civil, em 25.04.1984, a denominada **“PEC Dante de Oliveira”** foi rejeitada. Diante dessa situação, o Colégio Eleitoral acabou elegendo, em 15.01.1985, embora pelo **voto indireto**, pela primeira vez, após mais de 20 anos de ditadura militar, um civil — o que caracterizou o fim do regime militar —, **Tancredo Neves**, mineiro de São João Del Rei, que prometeu estabelecer a “Nova República”, democrática e social.

Sua posse estava marcada para o dia 15.02.1985, mas Tancredo Neves adoeceu gravemente na véspera, não tomou posse e veio a falecer, para tristeza e comoção do País, no dia 21.04.1985. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa — José Sarney (15.03.1985 a 15.03.1990), o Vice-Presidente, assumiu a presidência com importante particularidade: era o primeiro governo civil após o movimento militar de 1964.

Embora não tenha tomado posse em razão de sua enfermidade, a **Lei n. 7.465/86** incluiu o nome de **Tancredo Neves** na “**galeria dos que foram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema Magistratura**”, ou seja, na galeria dos **Ex-Presidentes da República**.[118](#)

Na medida em que Tancredo Neves sempre cogitou da elaboração de uma “Comissão de Notáveis” para elaborar um anteprojeto de Constituição, José Sarney, o novo Presidente, considerando o compromisso assumido pela Aliança Democrática perante a Nação, instituiu, pelo Decreto n. 91.450/1985, junto à Presidência da República, uma **Comissão Provisória de Estudos Constitucionais**, composta de 50 membros de livre escolha do Chefe do Executivo e com o objetivo de desenvolver pesquisas e estudos fundamentais, no interesse da Nação brasileira, para futura colaboração com os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.

Essa Comissão, conhecida por **Comissão Afonso Arinos**, nome de seu presidente, entregou um anteprojeto de Constituição em 18.09.1986, que foi publicado no *DOU* de 26.09.1986, com 436 artigos no corpo e 32 nas Disposições Gerais e Transitórias.

O texto final elaborado pela *Comissão Afonso Arinos*, todavia, foi rejeitado por José Sarney, tendo em vista, entre outras razões, ter optado pelo sistema **parlamentarista**, o que diminuiria os poderes do Presidente.

Em seguida, buscando cumprir o mandamento da EC n. 26, de 27.11.1985,[119](#) que determinou a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, finalmente ela foi instalada, mesmo sem partir de um projeto previamente elaborado, em 1.º.02.1987, sob a presidência do Ministro do STF José Carlos Moreira Alves.

Como anota Barroso, “além das dificuldades naturais, advindas da heterogeneidade das visões políticas, também a metodologia de trabalho utilizada contribuiu para as deficiências do texto final. Dividida, inicialmente, em 24 subcomissões e, posteriormente, em 8 comissões, cada uma delas elaborou um anteprojeto parcial, encaminhado à Comissão de Sistematização. Em 25 de junho do mesmo ano, o relator desta Comissão, Deputado Bernardo Cabral,

apresentou um trabalho em que reuniu todos estes anteprojetos em uma peça de 551 artigos! A falta de coordenação entre as diversas comissões, e a abrangência desmesurada com que cada uma cuidou de seu tema, foram responsáveis por uma das maiores vicissitudes da Constituição de 1988: as superposições e o detalhismo minucioso, prolixo, casuístico, inteiramente impróprio para um documento dessa natureza. De outra parte, o assédio dos *lobbies*, dos grupos de pressão de toda ordem, gerou um texto com inúmeras esquizofrenias ideológicas e densamente corporativo”. [120](#)

Depois de tanto trabalho e dificuldades, como se sabe, a Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro, redemocratizando o País, com importantes avanços.

Trata-se da denominada por **Ulysses Guimarães**, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, **Constituição Cidadã**, tendo em vista a ampla **participação popular** durante a sua elaboração e a constante busca de efetivação da **cidadania**.

■ 2.6.11. Constituição de 1988

Durante o governo *Sarney*, o **pluripartidarismo foi ampliado**, legalizando-se partidos como o PCB e o PC do B, surgindo novos como o PSDB (dissidência de membros do PMDB) e o PL (Partido Liberal), formado por ideais neoliberais do empresariado. Outro avanço foi a erradicação da “famigerada” censura à imprensa, que assolou o País durante o governo militar. O sindicalismo e grandes centrais (CUT e CGT) consolidaram-se.

Era a solidificação da transição entre o antigo regime e a “Nova República”. Em 1989, depois de 25 anos de regime de exceção, o povo elegia, pelo voto direto, em dois turnos, *Fernando Collor de Mello* (15.03.1990 a 29.12.1992). Tendo em vista os vários escândalos de corrupção, em 02.10.1992, a Câmara dos Deputados autoriza a abertura do processo de *impeachment*. Em 29.12.1992, Collor renuncia ao mandato e os Senadores aprovam sua inabilitação política por 8 anos.

O Vice-Presidente de Collor, *Itamar Franco* (29.12.1992 a 1.º.01.1995) assume interinamente a Presidência da República.

Em seguida, tivemos a eleição direta do sociólogo *Fernando Henrique Cardoso* (1.º.01.1995 a 1.º.01.1999) para mandato de 4 anos (mandato reduzido de 5 anos — redação original do texto de 1988 — para 4 anos, por força da EC de Revisão n. 5, de 07.06.1994). Durante o seu mandato, foi aprovada a EC n. 16, de 04.06.1997, que, mantendo o mandato de 4 anos, permitiu uma única reeleição subsequente.

Com fundamento na nova redação conferida aos arts. 82 e 14, § 5.º, Fernando Henrique se torna o primeiro presidente da história da República reeleito para um período subsequente (1.º.01.1999 a 1.º.01.2003).

Posteriormente, e também de forma democrática pelo voto direto, o povo elege o metalúrgico de Garanhuns-PE, *Luiz Inácio Lula da Silva*, que exerceu seu primeiro mandato de 1.º.01.2003 a 1.º.01.2007. Lula foi reeleito em outubro de 2006 (em 2.º turno, com 60,83% dos votos válidos, em disputa com Geraldo Alckmin), assumindo o novo mandato em 1.º.01.2007 e permanecendo até 1.º.01.2011, quando o Executivo Federal passou a ter por Chefe *Dilma Rousseff*, a **primeira mulher** em toda história da nossa República.

■ **Plebiscito:** conforme já indicamos, tivemos o primeiro **plebiscito** no Brasil, com data inicial prevista para 7 de setembro de 1993 (art. 2.º do ADCT), antecipada para 21 de abril de 1993 pela EC n. 2/92. O **resultado** todos já conhecem, qual seja, a manutenção da **república constitucional** e do **sistema presidencialista de governo**.

Ainda, nos termos do art. 3.º do ADCT, que fixava a manifestação do **poder constituinte derivado revisor** após 5 anos contados da promulgação do texto, em 07.10.1993 foi instalada a sessão inaugural dos trabalhos de “revisão constitucional”.

Após 237 dias de trabalho, tendo recebido cerca de 30.000 propostas, foram elaborados 74 projetos de Emenda de Revisão, dos quais apenas **6** foram aprovados como EC de Revisão.

Além das citadas Emendas de Revisão, o texto original já foi alterado 88 vezes [121](#) (88 emendas constitucionais, fruto da manifestação do **poder constituinte derivado reformador**), sofrendo profundas modificações, tendo sido constantemente interpretadas as suas normas e preceitos pelo STF.

No **preâmbulo** da CF/88 foi instituído um Estado Democrático, destinado a assegurar os seguintes **valores supremos** de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias:

- o exercício dos direitos sociais e individuais;
- a liberdade;
- a segurança;
- o bem-estar;
- o desenvolvimento;
- a igualdade;
- a justiça.

Sendo **democrática e liberal**, a Constituição de 1988, que sofreu forte influência da Constituição portuguesa de 1976, foi a que apresentou maior **legitimidade popular**, podendo ser destacadas as seguintes características:

■ **Forma de Governo:** República, confirmada pelo plebiscito do art. 2.º do ADCT.

■ **Sistema de Governo:** presidencialista, confirmado pelo plebiscito do art. 2.º do ADCT.

■ **Forma de Estado:** Federação. Percebe-se sensível ampliação da autonomia administrativa e financeira dos Estados da Federação, bem como do Distrito Federal e Municípios. Inegavelmente, contudo, a União continua fortalecida, caracterizando-se o texto como centralizador.

Foi criado o Estado de Tocantins (art. 13 do ADCT), e os Territórios Federais

de Roraima e do Amapá foram transformados em Estados Federados (art. 14 do ADCT). O Território Federal de Fernando de Noronha foi extinto, e sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco (art. 15 do ADCT).

■ **Capital Federal:** nos termos do art. 18, § 1.º, **Brasília** é a Capital Federal. Assim, o Distrito Federal, ainda localizado no Planalto Central do Brasil, deixa de ser simples autarquia territorial e passa a ser considerado **ente federativo**, com autonomia político-constitucional, apesar de parcialmente tutelada pela União, como será estudado no *item 7.7.3*.

■ **Inexistência de religião oficial:** o Brasil é um país leigo, laico ou não confessional, muito embora haja a previsão de “Deus” no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** foi retomada a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu. Diferentemente do regime anterior, buscou-se um maior equilíbrio, especialmente pela técnica dos “freios e contrapesos”, abrandando a supremacia do Executivo, que imperava.

■ **Poder Legislativo:** bicameral, exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a primeira composta de representantes do povo, eleitos pelo voto direto, secreto e universal e pelo sistema proporcional para mandato de 4 anos, e a segunda composta de representantes dos Estados-Membros e do Distrito Federal, para mandato de 8 anos (duas legislaturas), eleitos pelo sistema majoritário, sendo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3.

■ **Poder Executivo:** exercido pelo Presidente da República, eleito junto com o Vice e auxiliado pelos Ministros de Estado. Atualmente, após a EC n. 16/97, como visto, o mandato é de 4 anos, permitindo-se uma única reeleição subsequente. O decreto-lei foi substituído pela medida provisória.

■ **Poder Judiciário:** nos termos do art. 92, são órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça (EC n. 45/2004); o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e

Juizes Federais; os Tribunais e Juizes do Trabalho; os Tribunais e Juizes Eleitorais; os Tribunais e Juizes Militares; os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e Territorios.

Em relação ao controle de constitucionalidade das leis, tema que será estudado, houve ampliação dos legitimados para a propositura da ADI.

A CF/88 criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal em todo o Brasil, sendo órgão de convergência da Justiça comum. Nesse sentido, o STF passou a cuidar de temas predominantemente constitucionais.

A EC n. 45/2004, *Reforma do Poder Judiciário*, trouxe importantes modificações.

■ **Constituição rígida:** existe um processo de alteração mais árduo, mais solene e mais dificultoso que o processo de alteração das demais espécies normativas, daí a rigidez constitucional.

■ **Declaração de direitos:**

- a) os princípios democráticos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos estão consolidados no texto, consagrando direitos fundamentais de maneira inédita, por exemplo, ter tornado o racismo e a tortura (que já havia sido abolida — art. 179, XIX, da Constituição de 1824) crimes **inafiançáveis**;
- b) os direitos dos trabalhadores foram ampliados;
- c) pela primeira vez se estabeleceu o controle das omissões legislativas, seja pelo mandado de injunção (controle difuso), seja pela ADI por omissão (controle concentrado), temas a serem estudados;
- d) introduziu-se a ADPF — arguição de descumprimento de preceito fundamental, tema a ser desenvolvido no capítulo sobre o controle de constitucionalidade;
- e) outros remédios também foram previstos pela primeira vez no texto, quais sejam, o mandado de segurança coletivo e o *habeas data*;

f) há previsão específica, pela primeira vez, de um capítulo sobre o “meio ambiente” (art. 225);

g) nesse sentido, destacam-se, dentre as funções institucionais do Ministério Público, a de promover o inquérito civil e a **ação civil pública**, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, *caput*, e 129, III). Lembramos que, de acordo com o art. 129, § 1.º, a legitimação do Ministério Público para as ações civis não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei; [122](#)

h) outra relevante função institucional do MP é a de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V);

i) importante previsão da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5.º, LXXIV. Por força das alterações promovidas pela Lei n. 11.448/2007 e pela LC n. 132/2009 (consagradas na EC n. 80/2014), a Defensoria tornou-se parte legítima para a propositura de ação civil pública, atribuição esta reconhecida como constitucional pelo Pleno do STF no julgamento da **ADI 3.943** (j. 07.05.2015, cf. *item 12.6.9.10*).

■ **Separação da Ordem Econômica e da Ordem Social:** a primeira Constituição brasileira a separar a *ordem econômica* da *ordem social* foi a de 1988.

A ordem econômica recebeu tratamento sistemático, pioneiramente, na Constituição do México de 1917. No Brasil, sob a influência da *Constituição de Weimar*, de 1919, a primeira a tratar da ordem econômica e da ordem social em título único (Título IV) foi a de **1934**.

A Constituição de 1937, embora mantendo as matérias sobre a ordem econômica e social, aboliu a utilização de títulos e passou a destacar, de modo simplificado, a ordem econômica.

As Constituições de 1946, 1967 e a EC n. 1/69 seguiram a mesma estrutura

da de 1934, agregando a ordem econômica e a ordem social em um único título.

A Constituição de 1988, conforme visto, inova e passa a tratar da ordem social em título próprio, **desvinculando-a** da ordem econômica que, por sua vez, recebe matérias sobre o sistema financeiro nacional (Título VII). Alguns temas da ordem social que eram assegurados nas Constituições anteriores, como os *direitos dos trabalhadores*, foram deslocados para o Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais (direitos sociais).

■ 2.7. QUESTÕES

■ 2.7.1. Conceito, classificação e elementos das Constituições

1. É correto dizer que a diferença entre Constituição rígida e flexível está no fato de esta última poder ser alterada e aquela não?

2. (Ministério da Saúde — Analista Técnico — Administrativo — PGPE 1 — CESPE/UnB/2010) Em um país que possua uma Constituição flexível, caso seja editada uma lei com conteúdo contrário ao texto constitucional, essa lei será válida e acarretará alteração da Constituição.

3. (Analista de Correios/Advogado — CESPE/UnB/2011) Segundo os doutrinadores, a ideia de uma Constituição aberta está ligada à possibilidade de sua permanência dentro de seu tempo, evitando-se o risco de perda ou desmoronamento de sua força normativa.

4. (DP/RJ — CEPERJ 2009) Diz-se que a Constituição brasileira de 1988 é rígida porque:

- a) não admite a ocorrência do fenômeno da mutação constitucional;
- b) classifica como inafiançáveis os crimes de racismo e tortura, entre outros;
- c) prevê, para sua reforma, a adoção de procedimento mais complexo, em tese, do que o adotado para a modificação das leis;
- d) estabelece penalidades severas para os crimes de responsabilidade;
- e) foi promulgada por Assembleia Nacional Constituinte convocada na forma de Emenda à

Constituição anterior.

5. (80.º/MP/SP/1998) A Constituição que, resultante dos trabalhos de um órgão constituinte, sistematiza as ideias e os princípios fundamentais de teoria política e do Direito dominante no momento, quanto ao modo de sua elaboração, denomina-se:

- a) flexível;
- b) formal;
- c) semirrígida;
- d) outorgada;
- e) dogmática.

6. (MP/MA 2009) A Constituição Federal atual pode ser classificada como:

- a) rígida, codificada, outorgada e concisa;
- b) flexível, legal, promulgada e prolixa;
- c) rígida, codificada, promulgada e prolixa;
- d) flexível, legal, outorgada e concisa; e
- e) flexível, codificada, outorgada e concisa.

7. (Magistratura-MG/02-03) A classificação das Constituições em “Constituição normativa, Constituição nominal e Constituição semântica” foi formulada por:

- a) Carré de Malberg;
- b) Carl Schmitt;
- c) Georges Burdeau;
- d) Gomes Canotilho;
- e) Karl Loewenstein.

8. (AGU — CESPE/UnB/2010) No que se refere ao conceito e à classificação de Constituição, julgue o próximo item:

Segundo a doutrina, quanto ao critério ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional, é possível classificar as constituições em normativas, nominalistas e semânticas.

9. (PGE/MA-2003) A Constituição “como decisão política do titular do poder constituinte” é conceito atribuído a:

- a) Sieyès;
- b) Kelsen;
- c) Montesquieu;
- d) Carl Schmitt;
- e) Ferdinand Lassalle.

10. (VIII Concurso PGE/MS — 14.11.2004) Julgue cada uma das proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

- I — Na concepção teórica da Constituição em sentido ontológico, de Karl Loewenstein, uma das classificações que se apresenta é a de Constituição semântica, que é aquela cujas normas dominam o processo político, ou seja, quando o processo político se submete às normas constitucionais;
 - II — Toda Constituição tem como atributo a denominada supremacia material, posto que costumeiras e flexíveis, enquanto a supremacia formal só se apresenta nas Constituições escritas e rígidas, pois nestas se estabelece um procedimento solene e com maiores formalidades para a alteração (reforma) de suas normas em relação ao direito infraconstitucional;
 - III — No sentido sociológico, conforme a doutrina de Ferdinand Lassalle, a Constituição é concebida como o *modo de se combinarem os distintos fatores reais de poder que compõem o Estado*;
 - IV — Na teoria geral do Direito Constitucional encontramos a posição de Carl Schmitt; segundo este mestre germânico a Constituição deve ser compreendida em *sentido político* e dessa sua posição resultou a formulação da *teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico*;
 - V — A fórmula de que *a Constituição é uma norma jurídica escrita suprema de um Estado e, ao mesmo tempo, fundamento lógico superior de toda a ordem jurídica* foi delineada por Hans Kelsen, em sua concepção da Constituição em *sentido jurídico*.
- a) As proposições I, III e V estão incorretas;
 - b) As proposições II, III e V estão corretas;
 - c) As proposições I, II e III estão corretas;
 - d) As proposições III, IV e V estão incorretas;
 - e) Todas as proposições estão corretas.

11. (TRT 24.^a Região/MS/2007) Considere as referências abaixo acerca dos

conceitos de Constituição:

- I. Constituição no sentido lógico-jurídico.
- II. Constituição no sentido jurídico-positivo.
- III. Constituição como decisão política fundamental.

Faça a correlação com as referências a seguir:

- (A) Significa a norma fundamental hipotética.
- (B) A Constituição é dimensionada como decisão global e fundamental advinda da unidade política, e identificável pelo núcleo de matérias que lhe são próprias e inerentes.
- (C) Equivale à norma positiva suprema.

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que expressa a relação correta entre as referências acima:

- a) (I-C); (II-A); (III-B).
- b) (I-A); (II-B); (III-C).
- c) (I-A); (II-C); (III-B).
- d) (I-B); (II-C); (III-A).
- e) (I-C); (II-A); (III-C).

12. (DP/SP/2006 — FCC) O termo “Constituição” comporta uma série de significados e sentidos. Assinale a alternativa que associa corretamente frase, autor e sentido.

- a) Todos os países possuem, possuíram sempre, em todos os momentos da sua história uma Constituição real e efetiva. Carl Schmitt. Sentido político.
- b) Constituição significa, essencialmente, decisão política fundamental, ou seja, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma de existência política. Ferdinand Lassale. Sentido político.
- c) Constituição é a norma fundamental hipotética e lei nacional no seu mais alto grau na forma de documento solene e que somente pode ser alterada observando-se certas prescrições especiais. Jean Jacques Rousseau. Sentido lógico-jurídico.
- d) A verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais do poder que naquele país vigem e as Constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que expressem fielmente os fatores do poder que imperam na realidade. Ferdinand Lassale. Sentido sociológico.
- e) Todas as Constituições pretendem, implícita ou explicitamente, conformar globalmente o político. Há uma intenção atuante e conformadora do direito constitucional que vincula o

legislador. Jorge Miranda. Sentido dirigente.

13. (PGE/AP/2006 — CESPE/UnB) A Constituição brasileira de 1946 era semirrígida porque continha algumas normas que poderiam ser alteradas por emendas constitucionais e outras que, por serem cláusulas pétreas, eram insuscetíveis de alteração por ato do poder constituinte derivado.

14. (MP/ENAP/SPU/ADM/Conhecimentos Gerais/2006/ESAF) Sobre Teoria Geral do Estado e da Constituição; Poderes do Estado; Supremacia da Constituição e tipos de Constituição, assinale a única opção correta.

- a) Na concepção sociológica, defendida por Ferdinand Lassale, a Constituição seria o resultado de uma lenta formação histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, que se cristalizam como normas fundamentais da organização de determinado Estado.
- b) Da autoprímazia normativa, característica da norma constitucional, decorre o princípio da conformidade, segundo o qual nenhum ato do poder político — legislativo, executivo ou judiciário — pode ser praticado em desacordo com as normas e os princípios constitucionais.
- c) Constituições rígidas são as que possuem cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado.
- d) As Constituições classificadas quanto à forma como legais são aquelas sistematizadas e apresentadas em um texto único.
- e) Segundo a doutrina, são características das Constituições concisas: a menor estabilidade do arcabouço constitucional e a maior dificuldade de adaptação do conteúdo constitucional.

15. (MP/RN-CESPE/UnB 2009) A Carta outorgada em 10.11.1937 é exemplo de texto constitucional colocado a serviço do detentor do poder, para seu uso pessoal. É a máscara do poder. É uma Constituição que perde normatividade, salvo nas passagens em que confere atribuições ao titular do poder. Numerosos preceitos da Carta de 1937 permaneceram no domínio do puro nominalismo, sem qualquer aplicação e efetividade no mundo das normas jurídicas. Raul Machado Horta. Direito constitucional. 2.^a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 54-5 (com adaptações). Considerando a classificação ontológica das Constituições, assinale a opção que apresenta a categoria que se aplica à Constituição de 1937, conforme a descrição

acima.

- a) Constituição semântica.
- b) Constituição dogmática.
- c) Constituição formal.
- d) Constituição outorgada.
- e) Constituição ortodoxa.

16. (Auditor-Fiscal do Trabalho/2006/ESAF) Na concepção materialista de Constituição, é dada relevância ao processo de formação das normas constitucionais, que, além de ser intencional, deve produzir um conjunto sistemático, com unidade, coerência e força jurídica próprias, dentro do sistema jurídico do Estado.

17. (Analista de Finanças e Controle-STN/2006/ESAF) Na concepção de Constituição em seu sentido político, formulada por Carl Schmitt, há uma identidade entre o conceito de Constituição e o conceito de leis constitucionais, uma vez que é nas leis constitucionais que se materializa a decisão política fundamental do Estado.

18. (Analista de Finanças e Controle — AFC — CGU/2006/ESAF) Sobre conceito e classificação da Constituição e poder constituinte, assinale a única opção correta:

- a) O conceito formal de Constituição e o conceito material de Constituição, atualmente, se confundem, uma vez que a moderna teoria constitucional não mais distingue as normas que as compõem.
- b) Quanto ao sistema da Constituição, as Constituições se classificam em Constituição principiológica — na qual predominam os princípios — e Constituição preceitual — na qual prevalecem as regras.

19. (PGE-PB/CESPE/UnB/2008) Acerca do conceito, do objeto, dos elementos e da classificação das Constituições, assinale a opção correta.

- a) A Constituição é, na visão de Ferdinand Lassalle, uma decisão política fundamental, e não uma mera folha de papel.
- b) Para Carl Schmitt, o objeto da Constituição são as normas que se encontram no texto constitucional, não fazendo qualquer distinção entre normas de cunho formal ou material.
- c) O dispositivo constitucional que arrola os princípios gerais da atividade econômica, como

o da propriedade privada e sua função social, é considerado elemento socioideológico da Constituição, revelador do compromisso de um Estado não meramente individualista e liberal.

- d) Como, no Brasil, a CF admite mudança por meio de emenda à Constituição, respeitados os limites por ela impostos, ela é considerada semirrígida.
- e) A distinção entre Constituição formal e material é relevante para fins de aferição da possibilidade de controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais.

20. (Delegado-TO/CESPE/UnB/2008) Os elementos orgânicos que compõem a Constituição dizem respeito às normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, fixando o sistema de competência dos órgãos, instituições e autoridades públicas.

21. (TCE-ES — Procurador Especial de Contas — CESPE/UnB/2009) No que se refere aos elementos e à classificação das constituições, assinale a opção correta:

- a) Quanto ao modo de elaboração, a Constituição dogmática decorre do lento processo de absorção de ideias, da contínua síntese da história e das tradições de determinado povo.
- b) Sob o ponto de vista da extensão, a Constituição analítica consubstancia apenas normas gerais de organização do Estado e disposições pertinentes aos direitos fundamentais.
- c) O preâmbulo, o dispositivo que estabelece cláusulas de promulgação e as disposições transitórias são exemplos de elementos de estabilização constitucional.
- d) Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos limitativos das constituições.
- e) Os denominados elementos formais de aplicabilidade das constituições são consagrados nas normas destinadas a garantir a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.

22. (Delegado de Polícia Civil/RN — CESPE/UnB/2009) Acerca dos sentidos, dos elementos e das classificações atribuídos pela doutrina às constituições, assinale a opção correta.

- a) O elemento de estabilização constitucional é consagrado nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.
- b) O elemento socioideológico é assim denominado porque limita a ação dos poderes

estatais e dá a tônica do estado de direito, consubstanciando o elenco dos direitos e garantias fundamentais.

- c) Quanto à forma, diz-se formal a Constituição cujo texto é composto por normas materialmente constitucionais e disposições diversas que não tenham relação direta com a organização do Estado.
- d) Segundo o sentido sociológico da Constituição, na concepção de Ferdinand Lassalle, o texto constitucional equivale à norma positiva suprema, que regula a criação de outras normas.
- e) Segundo o sentido político da Constituição, na concepção de Carl Schmitt, o texto constitucional equivale à soma dos fatores reais de poder, não passando de uma folha de papel.

23. (Magistratura/TJ/PB — CESPE/UnB/2011) Com relação ao objeto, aos elementos e aos tipos de Constituição, assinale a opção correta:

- a) Quanto ao modo de elaboração, a vigente CF pode ser classificada como uma Constituição histórica, em oposição à dita dogmática.
- b) O objeto da CF é a estrutura fundamental do Estado e da sociedade, razão por que somente as normas relativas aos limites e às atribuições dos poderes estatais, aos direitos políticos e individuais dos cidadãos compõem a Constituição em sentido formal.
- c) Por limitarem a atuação dos poderes estatais, as normas que regulam a ação direta de inconstitucionalidade e o processo de intervenção nos estados e municípios integram os elementos ditos limitativos.
- d) Os elementos formais de aplicabilidade são exteriorizados nas normas constitucionais que prescrevem as técnicas de aplicação delas próprias, como, por exemplo, as normas inseridas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
- e) Distintamente da Constituição analítica, a Constituição dirigente tem caráter sintético e negativo, pois impõe a omissão ou negativa de ação ao Estado e preserva, assim, as liberdades públicas.

24. (TRF-5 — CESPE/UnB/2009) Acerca do conceito, dos elementos e da classificação da CF, do poder constituinte e da hermenêutica constitucional, assinale a opção correta:

- a) De acordo com o princípio da força normativa da Constituição, defendida por Konrad Hesse, as normas jurídicas e a realidade devem ser consideradas em seu condicionamento recíproco. A norma constitucional não tem existência autônoma em

face da realidade. Para ser aplicável, a CF deve ser conexa à realidade jurídica, social e política, não sendo apenas determinada pela realidade social, mas determinante em relação a ela.

- b) Segundo Kelsen, a CF não passa de uma folha de papel, pois a CF real seria o somatório dos fatores reais do poder. Dessa forma, alterando-se essas forças, a CF não teria mais legitimidade.
- c) A CF admite emenda constitucional por meio de iniciativa popular.
- d) Segundo Pedro Lenza, os elementos limitativos da CF estão consubstanciados nas normas constitucionais destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.
- e) Constituição rígida é aquela que não pode ser alterada.

25. (Defensoria Pública/SP — 2010) A “Constituição Dirigente” determina tarefas, estabelece metas e programas e define fins para o Estado e para a sociedade. Nesse modelo:

- a) são insindicáveis as políticas públicas no que se refere aos meios necessários para atingi-las, pois é nesse aspecto que reside a discricionariedade do Governante;
- b) não se aplica o controle de constitucionalidade das políticas governamentais, pois o Poder Judiciário não tem legitimidade, nem atribuição sem que se viole a separação de poderes;
- c) não cabe controle de constitucionalidade de “questões políticas” desde a Constituição de 1934 que expressamente vedava ao Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas;
- d) é cabível juízo de constitucionalidade de políticas públicas que podem ser consideradas incompatíveis com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado;
- e) não é suscetível de controle de constitucionalidade as normas de caráter programático que integram o núcleo político da Constituição, mas não o normativo.

26. (87.º Concurso — MP/SP) Quanto ao grau de sua alterabilidade ou mutabilidade, as Constituições Federais se classificam em:

- a) flexíveis, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis, e super-rígidas;
- b) promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas;
- c) analíticas e sintéticas;
- d) escritas e costumeiras;

e) rígidas e super-rígidas.

27. (Procurador Jurídico da USP/FUVEST — 2011) Sobre as denominadas constituições heterônomas ou heteroconstituições, é correto afirmar que:

- a) são constituições formuladas por Assembleias Constituintes eleitas pelo voto popular com esta única e exclusiva missão.
- b) consistem em constituições inorgânicas que, além de seus textos normativos, têm em sua composição tratados e convenções internacionais devidamente incorporados pelo Poder Legislativo ao ordenamento interno.
- c) são constituições destituídas de origem democrática, impostas unilateralmente mediante o uso da força pelos detentores do poder.
- d) são constituições decretadas externamente ao próprio Estado por outros países, ou ainda por organizações internacionais.
- e) se caracterizam por disciplinar, além da organização política do Estado e dos direitos fundamentais, questões relacionadas a diversas outras áreas do direito.

28. (TCE-ES — Auditor de Controle Externo — Auditoria Governamental — CESPE/UnB/2012) Acerca (...) dos elementos da CF, julgue o item a seguir:

Denominam-se elementos orgânicos da CF os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas relativas à organização do Estado.

29. (PRF — Agente Administrativo — Classe A — Padrão I — CESPE/UnB/2012) Com relação (...) ao conceito de Constituição, julgue o item a seguir:

Na concepção sociológica de Constituição, Constituição e lei constitucional têm a mesma acepção.

30. (PRF — Agente Administrativo — Classe A — Padrão I — CESPE/UnB/2012) Com relação (...) às classificações (...) de Constituição, julgue o item a seguir:

Em relação ao conteúdo, a CF deve ser classificada como analítica.

31. (ANAC — Técnico Administrativo — CESPE/UnB/2012) Julgue o item seguinte, relativo à classificação das Constituições:

Uma Constituição pode ser classificada como não escrita quando suas normas não se encontram sistematizadas em um documento único. Tais constituições são compostas por costumes, pela jurisprudência e também por instrumentos escritos dispersos no

tempo.

32. (TRE-RJ — Técnico Judiciário — Área Administrativa — CESPE/UnB/2012) (...)

Julgue o item a seguir:

Segundo Ferdinand Lassale, a Constituição de um país somente pode ser considerada legítima se de fato representar o efetivo poder social, ou seja, se refletir as forças sociais que constituem o poder.

33. (TJ-RR — Técnico Judiciário — CESPE/UnB/2012) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte:

A CF pode ser classificada, quanto à mutabilidade, como rígida, uma vez que não pode ser alterada com a mesma simplicidade com a qual se modifica uma lei.

34. (DPE-RR — CESPE/UnB/2013) Assinale a opção correta referente à classificação das constituições (...). (adaptada — prova original com cinco alternativas):

- a) No que se refere à classificação das constituições quanto ao sistema, a denominada constituição preceitual é aquela na qual há a predominância de princípios, considerados normas constitucionais, com elevado grau de abstração e generalidade, a exemplo da CF.
- b) Quanto à origem, a chamada constituição cesarista independe de ratificação popular por referendo.

35. (Procurador do BACEN — CESPE/UnB/2013) A respeito do conceito, dos elementos e das classificações das constituições, assinale a opção correta:

- a) No que se refere ao modo de elaboração, a constituição dogmática espelha os dogmas e princípios fundamentais adotados pelo Estado e não será escrita.
- b) Quanto à estabilidade, a constituição flexível não se compatibiliza com a forma escrita, ainda que seu eventual texto admitisse livre alteração do conteúdo por meio de processo legislativo ordinário.
- c) Os direitos e garantias fundamentais previstos na CF são considerados elementos socioideológicos.
- d) No sentido político, segundo Carl Schmitt, a constituição é a soma dos fatores reais do poder que formam e regem determinado Estado.
- e) Quanto aos elementos, o ADCT configura exemplo de elemento formal de aplicabilidade da CF.

36. (Procurador Municipal — Prefeitura de Cachoeirinha/RS — FUNDATEC/2012) De acordo com a doutrina de Pedro Lenza, na obra Direito Constitucional Esquematizado, a Constituição Federal atual pode ser classificada como:

- a) promulgada, escrita, analítica e formal.
- b) promulgada, consuetudinária, analítica e formal.
- c) promulgada, escrita, analítica e material.
- d) outorgada, escrita, analítica e material.
- e) outorgada, escrita, analítica e formal.

■ 2.7.2. Histórico das Constituições brasileiras

1. (TJM/SP/2007/VUNESP) Assinale a alternativa correta:

- a) A Constituição do Império foi outorgada pela metrópole, e previa Estado unitário, três Poderes e religião estatal.
- b) A Constituição editada em 25 de março de 1824 não adotava o Catolicismo como religião oficial.
- c) A Constituição republicana de 1891 foi outorgada pelo Presidente da República, adotou o regime presidencialista, e previa Estado federado, três Poderes e estado confessional.
- d) A Constituição de 1937 foi outorgada pelo Congresso Nacional, previa Estado unitário, três Poderes com acentuado fortalecimento do Executivo e autorização para edição de Decretos-lei pelo Presidente da República.
- e) A Constituição de 1946 foi promulgada, previa Estado federado, reorganizou os direitos e garantias individuais e vigorou, com as respectivas Emendas, até a promulgação da Constituição de 1967, esta última oriunda de projeto apresentado pelo governo e votada sob o procedimento estabelecido pelo Ato Institucional n. 4.

2. (Magistratura/TRF5/2007) Julgue os próximos itens, relacionados à evolução do constitucionalismo brasileiro.

- I. O prenúncio da redemocratização do Brasil foi, em 1984, o movimento civil Diretas Já, de reivindicação por eleição presidencial direta no Brasil, a qual se concretizou na aprovação, com expressiva votação pelo Congresso Nacional, da proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que permitiu a volta dos civis ao poder e a subsequente eleição de Tancredo Neves.
- II. Na Constituição de 1891, adotou-se como forma de governo para o país a República

Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e consagrou-se a dualidade da justiça, a federal e a estadual, além de se instituir o STF.

- III. Fruto das revoluções de 1930 e 1932 e espelhando as grandes transformações do século XX, especialmente o fim da 1.^a Guerra Mundial, a Constituição de 1934 foi simplesmente desconsiderada pelo golpe de Estado de 1937 e pela outorga, por Getúlio Vargas, da nova Carta política, que, de inspiração fascista, teve como autor principal Francisco Campos.
- IV. A Constituição de 1946 era muito parecida com a de 1934 devido à coincidência de fatores políticos que marcaram a sua elaboração: a de 1934 constituiu forte reação à República Velha, e a de 1946, às tendências ditatoriais. Portanto, ambas, pode-se dizer, tiveram inspiração democrática.
- V. A Constituição de 1967 foi emendada em 1969 pelo Congresso Nacional, mantendo-se, pelo menos formalmente, as eleições presidenciais pelo sistema do sufrágio universal e o voto direto e secreto.

3. (AGU/Procurador Federal/CESPE/UnB/2007) A história constitucional do Brasil, de conhecimento indispensável a quem busca estudar nossas instituições políticas e sociais, representa um dos mais profundos mergulhos na compreensão do passado nacional. O exame e a análise dos sucessos políticos e das raízes institucionais do país não de trazer sempre luz para o entendimento da realidade contemporânea, na qual os acontecimentos transcorrem com a velocidade da crise e fazem, não raro, extremamente difícil a percepção das causas que de imediato devem ser removidas, em escala prioritária, a fim de se poder fazer estável e seguro o destino da Nação e a preservação de sua unidade (Paulo Bonavides e Paes de Andrade. *História constitucional do Brasil*. Brasília: OAB Editora, 2002 — com adaptações). Julgue os itens subsequentes, que tratam da evolução constitucional no Brasil:

- a) A CF trouxe grandes avanços na área dos direitos e das garantias fundamentais, atestando a modernidade e fazendo do racismo e da tortura crimes inafiançáveis, estabelecendo o *habeas data* e reforçando a proteção dos direitos e das liberdades constitucionais, e restituindo ao Congresso Nacional prerrogativas que lhe haviam sido subtraídas pela administração militar.
- b) O período constitucional do Império foi o período da história brasileira em que o poder mais se apartou da Constituição formal, a qual teve baixo grau de eficácia e pouca presença na consciência dos dirigentes do país. Exemplo disso foi a não utilização da

Constituição como instrumento para se solucionar a questão da escravidão no Brasil.

4. (PGE-PI/CESPE/UnB/2008) Considerando a evolução constitucional no Brasil, assinale a opção correta:

- a) A Constituição de 1937 trouxe diversos avanços no campo do controle de constitucionalidade das normas, conferindo ao STF amplos poderes para exercer o controle abstrato e concreto de constitucionalidade.
- b) A Constituição de 1988 ampliou o rol de direitos e garantias individuais, prevendo, pela primeira vez, nas constituições brasileiras, o mandado de segurança e a ação popular.
- c) Uma das inovações trazidas pela Constituição brasileira de 1891 foi a divisão do território brasileiro em estados e a ampla liberdade de culto, com o fim do catolicismo como religião oficial do Estado.
- d) A Constituição de 1934 ficou marcada pela sua longa duração e pelo seu cunho autoritário, que permitiu a concentração de poderes nas mãos do chefe do Poder Executivo.
- e) Entre as principais características da Constituição de 1967, pode-se citar o aprimoramento da Federação brasileira, com a descentralização de competências e o fortalecimento do princípio da separação dos poderes.

5. (FCC — 2010 — MPE-SE — Analista — Direito) Considerando a evolução constitucional do Brasil, analise:

- I. A Constituição do Estado Novo (1937) não contemplava os princípios da legalidade e da retroatividade das leis, assim como não previa o mandado de segurança.
- II. A Constituição Republicana (1891) instituiu a forma federativa de Estado atribuindo-lhe a competência remanescente e fortaleceu os direitos individuais como a garantia do *habeas corpus*.
- III. A Constituição de 1967, inspirada na Carta de 1934, ostentou forte tendência à descentralização político-administrativa da União com ampliação dos direitos individuais, especialmente do direito de propriedade.
- IV. A Constituição de 1946 deu ao Brasil a forma de Estado unitário com intensa centralização político-administrativa e em matéria de direitos fundamentais previu o *habeas data* e o mandado de injunção.

Nesses casos, está correto o que consta APENAS em

- a) II, III e IV.

- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I e II.
- e) I, III e IV.

6. (TJ/MA — Titular de Serviços de Notas e de Registros — IESES/2008) Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A Constituição de 1934 foi promulgada, ao passo que a de 1937 foi outorgada.
- b) A Constituição de 1891 foi promulgada.
- c) Das Constituições brasileiras, as duas primeiras eram semirrígidas.
- d) A Constituição de 1824 era semirrígida, já que previa a alteração de uma parte pelos chamados meios ordinários.

7. (Magistratura RJ — VUNESP/2011) Na evolução político-constitucional brasileira, o voto feminino no Brasil foi expressamente previsto pela primeira vez num texto constitucional na Constituição de:

- a) 1891.
- b) 1934.
- c) 1937.
- d) 1946.

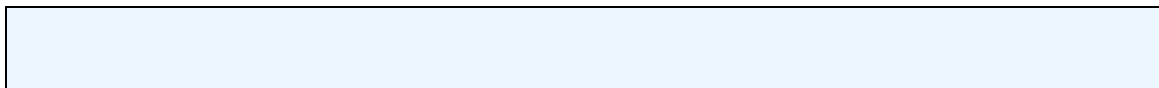
8. (ANTT — Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres — CESPE/UnB/2013) A respeito da ordem jurídico-econômica, julgue o item a seguir:

A primeira Constituição brasileira que separou a ordem econômica da ordem social foi a de 1988.

9. (ANTT — Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres — CESPE/UnB/2013) Marque certo ou errado:

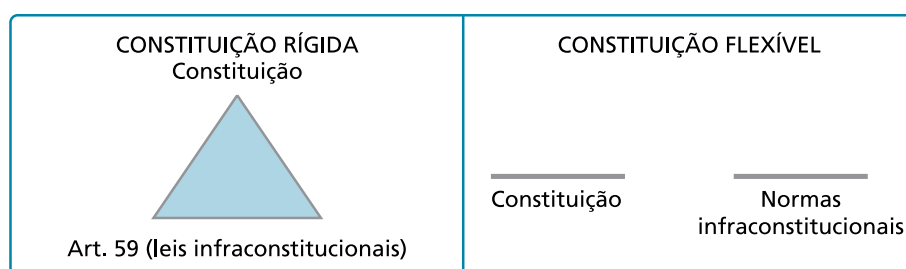
A primeira Constituição brasileira que tratou especificamente da ordem econômica foi a de 1946.

■ GABARITO ■



■ 2.7.1. Conceito, classificação e elementos das Constituições

1. Este é um equívoco comum. Cuidado: tanto a Constituição rígida como a flexível podem ser alteradas. A diferença entre elas está no processo legislativo de alteração da Constituição. Na rígida verificamos um processo legislativo mais árduo e mais solene do que o processo de alteração das leis ordinárias, enquanto na flexível a dificuldade de alteração da Constituição e das leis é a mesma, motivo por que, do ponto de vista formal, não existe hierarquia entre Constituição flexível e lei não constitucional ordinária.



2. “certo”.

3. “certo”.

4. “c”.

5. “e”.

6. “c”.

7. “e”.

8. “certo”.

9. “d”.

10. “b”. O item I está errado, pois estabelece, no fundo, a ideia de Constituição normativa, e não semântica. Como anota Paulo Ricardo Schier, “entenda-se, por Constituição normativa, aquela na qual o processo político, do poder, é dominado pelas normas da Constituição ou, pelo menos, adapta-se a elas. Toma-se, aqui, esta expressão, portanto, no sentido que lhe empresta Karl Loewenstein (*Teoría de la Constitución*, p. 216-231). Para este autor, buscando implementar uma

classificação ontológica da Constituição, deve-se entender por Constituição normativa aquela real e efetiva, observada lealmente por todos os interessados, devendo estar integrada na sociedade estatal, e esta nela” (Paulo Ricardo Schier, <i>Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática jurídica</i>, p. 96). O item IV está errado, pois, muito embora, de fato, Carl Schmitt tenha adotado Constituição no sentido político, como consequência de sua teoria poderíamos falar em Constituição e lei constitucional, e não em escalonamento do ordenamento jurídico (decorrência da teoria de Kelsen).
11. “c”. Itens I e II tratam da teoria de Kelsen; item III da de Carl Schmitt.
12. “d”.
13. O conceito de Constituição semirrígida está errado, já que é toda Constituição que tem algumas matérias que precisam de um processo mais árduo e mais solene para ser alterada e outras que não precisam de formalidades. O exemplo de semirrígida é a do Império de 1824 (art. 178).
14. “b”. A resposta correta vai ser desenvolvida no <i>item 3.6.4</i>, e foi extraída do livro de Canotilho. Segundo o mestre português, o direito constitucional “... caracteriza-se pela sua posição hierárquico-normativa superior relativamente às outras normas do ordenamento jurídico. Ressalvando algumas particularidades do direito comunitário, a superioridade hierárquico-normativa apresenta três expressões: (1) as normas do direito constitucional constituem uma <i>lex superior</i> que recolhe o fundamento de validade em si própria (autoprimazia normativa); (2) as normas da Constituição são <i>normas de normas (normae normarum)</i>, afirmando-se como uma fonte de produção jurídica de outras normas (leis, regulamentos e estatutos); (3) a superioridade normativa das normas constitucionais implica o princípio da conformidade de todos os actos dos poderes públicos com a Constituição...”. A letra “a” está errada pois Ferdinand Lassale fala da necessidade de a Constituição representar as forças sociais, sob pena de ser uma simples “folha de
de papel”. A letra “c” está errada porque as cláusulas pétreas podem ser modificadas para ser fortificadas e, segundo o STF, em qualquer sentido, desde que dentro da razoabilidade e não tenda a abolir as referidas cláusulas. A letra “d” está errada uma vez que constituições legais (também denominadas constituições escritas não formais e que equivalem às variadas de Pinto Ferreira) seriam aquelas escritas e que se apresentam esparsas ou fragmentadas em vários textos. A letra “e” está errada porque, em sentido contrário do que afirmado, é característica das

concisas uma maior estabilidade da Constituição.
15. “a”.
16. “errado”. Essa alternativa, retirada da questão 31 da prova, é errada, pois para as Constituições materiais não importa o processo legislativo de formação das normas constitucionais, mas a matéria, o seu conteúdo, que deverá conter as normas estruturais e fundamentais do Estado.
17. “errado”. Essa alternativa, retirada da questão 72 da prova comum, está errada, pois não há identidade entre Constituição e leis constitucionais, sendo que é a Constituição que materializa a decisão política fundamental.
18. “b”. <i>Vide</i> parte teórica.
19. “c”. <i>Vide</i> parte teórica.
20. “certo”. <i>Vide</i> parte teórica.
21. “d”. <i>Vide</i> parte teórica.
22. “a”. <i>Vide</i> parte teórica.
23. “d”. A letra “a” está errada, pois a CF/88 é classificada, quanto ao <i>modo de elaboração</i> , como dogmática. A letra “b” está errada, já que sugere normas estruturais e fundamentais, no caso, o verdadeiro sentido material e não formal de Constituição. A letra “c” está errada, porque referidas normas devem ser classificadas como elementos de estabilização. A letra “e” está errada, pois a Constituição dirigente estabelece um projeto de Estado e, assim, não tem caráter negativo nem espera a inação estatal.
24. “a”. A ideia de força normativa é retomada no <i>item 3.6.6</i> . De fato, conforme anota Hesse, “... a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade. A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. As possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição resultam da correlação entre ser (<i>Sein</i>) e dever ser (<i>Sollen</i>). (...). A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta de seu tempo. Todavia, ela não está

condicionada, simplesmente, por essa realidade...”. A letra “b” está errada, pois Kelsen adotou o sentido jurídico de Constituição. A letra “c” está errada na medida em que os legitimados para o encaminhamento de PEC (<i>Proposta de Emenda à Constituição</i>) estão taxativamente previstos no art. 60, não incluindo a iniciativa popular. Assim, a previsão não é expressa. Contudo, defendemos, por um processo hermenêutico, a sua possibilidade (cf. <i>item 9.13.3.4.4</i>). A letra “d” está errada, pois, conforme escrevemos na parte teórica, trata-se dos elementos de estabilização constitucional (cf. <i>item 2.5</i>). A letra “e” está errada, visto que a Constituição rígida pode ser alterada. O ponto é que a alteração exige um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas.
25. “d”.
26. “a”.
27. “d”. <i>Vide</i> parte teórica.
28. “certo”.
29. “errado”.
30. “errado”. Em relação ao conteúdo, conforme vimos na parte teórica, as Constituições se classificam em formal e material. Sintética e analítica são classificações quanto à extensão!
31. “certo”.
32. “certo”.
33. “certo”.
34. Ambas as alternativas estão <i>erradas</i> . Na primeira, devemos observar que nas constituições preceituais há a predominância das regras, e não dos princípios. A segunda proposição está errada porque a Constituição cesarista, ao contrário do proposto, depende da ratificação popular sobre o projeto elaborado pelo Imperador ou pelo Ditador.
35. “e”. A letra <i>a</i> está errada, pois as Constituições dogmáticas serão escritas e consubstanciam dogmas. A letra <i>b</i> está errada porque há, sim, compatibilidade entre a constituição flexível e a forma escrita. A letra <i>c</i> está errada porque os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição são considerados elementos limitativos. A letra <i>d</i> está errada na medida em que se

conceituou Constituição valendo-se do sentido sociológico de Ferdinand Lassale, e não do político de Carl Schmitt (decisão política do titular do poder constituinte).
36. “a”.
■ 2.7.2. Histórico das Constituições brasileiras
1. “e”. A letra “a” está errada porque havia, além dos três Poderes, o Poder Moderador. A letra “b” está errada, pois, ao contrário do afirmado, o Catolicismo era a religião oficial do Estado (aliás, foi a única que estabeleceu uma religião oficial). A letra “c” está errada já que o texto de 1891 foi promulgado e o Estado era não confessional. A letra “d” está errada porque a outorga foi pelo agente revolucionário, o ditador (e não pelo Congresso Nacional), e, ainda, a previsão formal era de um Estado federal (e não unitário), porém, conforme vimos, tratava-se de federalismo meramente nominal.
2. I-E — conforme estudado na parte teórica, de fato, a PEC Dante de Oliveira propunha as eleições diretas e despertou o movimento “Diretas Já”. Contudo, como se viu, referida PEC foi rejeitada, sendo a eleição do primeiro civil após 20 anos de ditadura — Tancredo Neves — indireta, pelo Colégio Eleitoral; II-C; III-C; IV-C; V-E — conforme estudamos, a EC n. 1/69 foi outorgada por uma Junta Militar, já que o Congresso Nacional estava fechado.
3. item a — “certo”: cf. art. 4.º, VIII, e art. 5.º, XLII, III e XLIII; item b — “certo”.
4. “c”. <i>Vide</i> parte teórica.
5. “d”. <i>Vide</i> parte teórica.
6. “c”. Conforme vimos na parte teórica, a única Constituição semirrígida no constitucionalismo brasileiro foi a de 1824, sendo as demais rígidas, ou seja, com um procedimento mais árduo e mais solene para a alteração.
7. “b”. De acordo com o art. 108, da Constituição de 1934, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.
8. “certo”. Cf. parte teórica.
9. “errado”. Conforme visto na parte teórica, foi a de 1934.

HERMENÊUTICA: MUTAÇÃO X REFORMA. REGRAS X PRINCÍPIOS. “DERROTABILIDADE”. POSTULADOS NORMATIVOS. CRIAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO

■ 3.1. MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS *VERSUS* REFORMAS CONSTITUCIONAIS

Neste tópico restringiremos a apresentação a alguns aspectos pontuais, sem, contudo, aprofundar a matéria. [1](#)

As Constituições devem ser interpretadas, função essa atribuída ao *exegeta*, que buscará o real significado dos termos constitucionais.

Tal função é extremamente importante, na medida em que a Constituição dará validade para as demais normas do ordenamento jurídico (Kelsen). Assim, devemos decifrar o seu verdadeiro alcance, a fim de sabermos, por consequência, a abrangência de uma norma infraconstitucional. [2](#)

O hermeneuta, dessa forma, levando em consideração a história, as ideologias, as realidades sociais, econômicas e políticas do Estado, definirá o

verdadeiro significado do texto constitucional.

Como regra fundamental, lembramos que, onde não existir dúvida, não caberá ao exegeta interpretar (*vide*, por exemplo, o art. 18, § 1.º, da CF/88, que aponta, como Capital Federal, Brasília — não cabendo qualquer trabalho hermenêutico).

A interpretação deverá levar em consideração todo o sistema. Em caso de antinomia de normas, buscar-se-á a solução do aparente conflito através de uma interpretação sistemática, orientada pelos princípios constitucionais.

Colocadas essas premissas, o **sentido** da Constituição **interpretada** pode mostrar-se **inadequado**. Nessas circunstâncias, dentro dos limites colocados pelo Constituinte originário, poderão ser observadas alterações tanto do ponto de vista **formal** (*reforma constitucional*) como do **informal** (*mutações constitucionais*).

Reforma constitucional seria a modificação do texto constitucional, mediante mecanismos definidos pelo poder constituinte originário (emendas), alterando, suprimindo ou acrescentando artigos ao texto original.³

As **mutações**, por seu turno, não seriam alterações “físicas”, “palpáveis”, materialmente perceptíveis, mas sim alterações no significado e sentido interpretativo de um texto constitucional. A transformação não está no texto em si, mas na interpretação daquela regra enunciada. O texto permanece inalterado.

As **mutações constitucionais**, portanto, exteriorizam o caráter **dinâmico** e de **prospecção** das normas jurídicas, por meio de **processos informais**. Informais no sentido de não serem previstos dentre aquelas mudanças formalmente estabelecidas no texto constitucional.

Buscando a sua origem na doutrina alemã, Uadi Lammêgo Bulos denomina **mutação constitucional** “... o processo informal de mudança da Constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da Constituição, quer através da interpretação, em suas diversas modalidades e métodos, quer por intermédio da construção (*construction*), bem como dos usos e dos costumes constitucionais”.⁴

Barroso, por sua vez, afirma que “... a mutação constitucional consiste em

uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura do que deve ser considerado ético ou justo. Para que seja legítima, a mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular”.[5](#)

Damos um exemplo, valendo-nos do Código Penal brasileiro, apenas para ilustrar: antes do advento da **Lei n. 11.106/2005**, os arts. 215, 216 e 219 do CP traziam a expressão “mulher honesta”. Quando falamos que essa expressão sofreu uma **mutação interpretativa**, não queremos dizer que o artigo em si foi alterado, mas, sim, que o conceito de “mulher honesta”, ao longo do tempo, levando em consideração os padrões aceitos pela sociedade da época, adquiriu significados diversos. “Mulher honesta” no começo do século XX tinha determinado significado, diverso do que adquire a “mulher honesta” dos dias atuais. “Mulher honesta” em uma cidade talvez tenha um significado diverso do que adquire em cidade de outra localidade.

Como visto, essa evolução da sociedade, que vinha sendo percebida pelo Judiciário, sensibilizou o legislador, que revogou por meio da Lei n. 11.106/2005 diversos dispositivos do CP, como os citados, que faziam menção à figura da “mulher honesta”.

Outro exemplo, agora de mutação constitucional, citado por Olavo Alves Ferreira, foi o cancelamento da Súmula 394 do STF, modificando o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função.[6](#)

Ainda, podemos lembrar a mudança de entendimento pelo STF sobre a competência para julgar HC impetrado em face de decisão de turma recursal, determinando a competência do TJ. Vejamos:

“Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, modificando sua jurisprudência, assentou a competência dos Tribunais de Justiça estaduais para

julgar *habeas corpus* contra ato de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, impõe-se a imediata remessa dos autos à respectiva Corte local para reinício do julgamento da causa, ficando sem efeito os votos já proferidos. Mesmo tratando-se de **alteração de competência** por efeito de **mutação constitucional** (nova interpretação à Constituição Federal), e não propriamente de alteração no texto da Lei Fundamental, o fato é que se tem, na espécie, hipótese de competência absoluta (em razão do grau de jurisdição), que não se prorroga. Questão de ordem que se resolve pela **remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**, para reinício do julgamento do feito” (HC 86.009-QO, Rel. Min. Carlos Britto, j. 29.08.2006, *DJ* de 27.04.2007).

Podemos destacar diversas outras interpretações dadas pelo STF ao instituto da “quarentena de entrada” (art. 93, I), à vedação da progressão de regime prevista na Lei de Crimes Hediondos, à anencefalia, à competência trabalhista para julgar ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho, à união homoafetiva, ao não cabimento da prisão civil do depositário infiel (cf. HC 91.361, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.09.2008, *DJE* de 06.02.2009) etc.

Sistematizando, a partir da doutrina clássica, Barroso⁷ procurou identificar os **mecanismos de mutação constitucional**, destacando-se:

■ **interpretação (judicial e administrativa):** em relação à interpretação judicial, podemos apontar os vários exemplos acima citados, sendo, assim, a evolução da jurisprudência da Corte inegável exteriorização da mutação constitucional. Ainda, essa evolução interpretativa poderá ser verificada, também, no âmbito administrativo. Como destaque, Barroso lembra a Res. n. 7/CNJ que, reconhecendo novas perspectivas aos princípios da impessoalidade e da moralidade, deu novo e restritivo sentido ao nepotismo;

■ **atuação do legislador:** verifica-se a mutação constitucional por atuação do legislador quando, por ato normativo primário, procurar alterar o sentido já dado a alguma norma constitucional. Como exemplo, depois de modificado o entendimento sobre a prerrogativa de foro pelo STF que, inclusive, conforme visto, cancelou a S. 394, o Congresso Nacional procurou resgatar o sentido dessa súmula, nos termos da Lei n.

10.628/2002. Cabe lembrar que o STF declarou inconstitucional referido ato normativo (cf. *item 9.9.2.3*);

■ **por via de costumes constitucionais:** o autor aduz não ser pacífica a existência de costumes em países de Constituição escrita e rígida.⁸ Porém, admite que certas práticas reiteradas ensejaram mudanças no sentido interpretativo da Constituição. Como exemplo, menciona a possibilidade de o Chefe do Poder Executivo negar a aplicação de lei que de modo fundamentado considere inconstitucional. Lembra, ainda, o voto de liderança no Parlamento, sem a submissão da matéria ao Plenário. Outro exemplo, antes do advento da EC n. 32/2001, destaca a reedição de medida provisória, desde que não houvesse expressa rejeição ou alteração do texto. Barroso evidencia, também, a evolução da interpretação em relação aos poderes da CPI, passando a Suprema Corte a admitir a quebra de sigilos bancários e fiscais.

Naturalmente, a mutação e a nova interpretação não poderão afrontar os **princípios estruturantes** da Constituição, sob pena de serem inconstitucionais.

■ 3.2. REGRAS E PRINCÍPIOS

A doutrina vem se debruçando sobre a importante e complexa distinção entre **regras** e **princípios**, partindo da premissa de que ambos são espécies de **normas** e que, como referenciais para o intérprete, **não** guardam, entre si, **hierarquia**, especialmente diante da ideia da **unidade** da Constituição.

Canotilho refere-se ao *sistema jurídico do Estado de direito democrático português* como **“um sistema normativo aberto de regras e princípios”**:

■ **sistema jurídico:** “porque é um sistema dinâmico de normas”;

■ **sistema aberto:** “porque tem uma estrutura *dialogica* (Caliess) traduzida na disponibilidade e ‘capacidade de aprendizagem’ das normas constitucionais para captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da ‘verdade’ e da ‘justiça’”;

■ **sistema normativo:** porque a estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas é feita por meio de *normas*;

■ **sistema de regras e de princípios:** “pois as normas do sistema tanto podem revelar-se sob a forma de *princípios* como sob a sua forma de *regras*”.[9](#)

Humberto Ávila, por sua vez, esclarece que “... um sistema não pode ser composto somente de princípios, ou só de regras. Um sistema só de **princípios** seria demasiado **flexível**, pela ausência de guias claros de comportamento, ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e controle de poder. E um sistema só de **regras**, aplicadas de modo formalista, seria demasiado **rígido**, pela ausência de válvulas de abertura para o amoldamento das soluções às particularidades dos casos concretos. Com isso se quer dizer que, a rigor, não se pode dizer nem que os princípios são mais importantes do que as regras, nem que as regras são mais necessárias que os princípios. Cada **espécie normativa** desempenha funções diferentes e complementares, não se podendo sequer conceber uma sem a outra, e a outra sem a uma. Tal observação é da mais alta relevância, notadamente tendo em vista o fato de que a Constituição Brasileira é repleta de regras, especialmente de competência, cuja finalidade é, precisamente, alocar e limitar o exercício do poder”.[10](#)

Segundo Ávila, a *interpretação* e a *aplicação* de **princípios** e **regras** dar-se-ão com base nos **postulados normativos inespecíficos**, quais sejam, a **ponderação** (atribuindo-se pesos), a **concordância prática** e a **proibição de excesso** (garantindo a manutenção de um mínimo de eficácia dos direitos fundamentais), e *específicos*, destacando-se o postulado da **igualdade**, o da **razoabilidade** e o da **proporcionalidade**.[11](#)

Canotilho, no tocante à diferenciação, sistematiza a matéria, estabelecendo os seguintes **critérios**:[12](#)

■ **grau de abstração:** “os *princípios* são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, as *regras* possuem uma abstração relativamente reduzida”;

■ **grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto:** “os *princípios*, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as *regras* são

susceptíveis de aplicação direta”;

■ **carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito:** “os *princípios* são normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de Direito)”;

■ **“proximidade” da ideia de direito:** “os *princípios* são ‘*standards*’ juridicamente vinculantes radicados nas exigências de ‘justiça’ (DWORKIN) ou na ‘ideia de direito’ (LARENZ); as *regras* podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional”;

■ **natureza normogenética:** “os *princípios* são fundamentos de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a *ratio* de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante”.

Barroso, avançando, identifica uma distinção **qualitativa** ou **estrutural** entre *regras* e *princípios*.

Conforme anota, “... a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central. A mudança de paradigma nessa matéria deve especial tributo às concepções de *Ronald Dworkin* e aos desenvolvimentos a ela dados por *Robert Alexy*. A conjugação das ideias desses dois autores dominou a teoria jurídica e passou a constituir o conhecimento convencional da matéria”.¹³ E, em seguida, conclui:

■ **regras:** relatos descritivos de condutas a partir dos quais, mediante **subsunção**, havendo enquadramento do fato à previsão abstrata, chega-se à conclusão. Diante do conflito entre regras, apenas uma prevalece dentro da ideia do *tudo ou nada* (*all or nothing*). A “... **regra** somente **deixará de incidir** sobre a hipótese de fato que contempla se for **inválida**, se houver outra **mais específica** ou se **não estiver em vigor**” (ou seja, acrescente-se, critérios *hierárquico*, da *especialidade* ou *cronológico*);

■ **princípios:** a previsão dos *relatos* se dá de maneira mais abstrata, sem

se determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser analisado para que o intérprete dê o exato **peso** entre os eventuais princípios em **choque** (*colisão*). Assim, a aplicação dos princípios “não será no esquema *tudo ou nada*, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato”. Destaca-se, assim, a técnica da **ponderação** e do **balanceamento**, sendo, portanto, os princípios **valorativos** ou **finalísticos**.

Nessa linha, partindo da proposta de diferenciação formulada por Dworkin,¹⁴ Robert Alexy dela se afasta e **avança** ao caracterizar os **princípios** como **mandamentos** ou **mandados de otimização** (sendo esta a sua principal contribuição à ideia inicial). Em suas palavras:

■ **regras:** “... são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, **determinações** no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma **distinção qualitativa**, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio”;

■ **princípios:** “... normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, **mandamentos de otimização**, que são caracterizados por poderem ser **satisfeitos em graus variados** e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das **possibilidades jurídicas**. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes”.¹⁵

Cabe alertar que as teses sobre as distinções entre regras e princípios defendidas por Dworkin e Alexy **não se confundem**.

De acordo com Virgílio Afonso da Silva, “... não só as teses de ambos os autores não são idênticas — a própria ideia de otimização não está presente nas obras de Dworkin —, como também a possibilidade de única resposta correta é rejeitada expressamente pela teoria dos princípios na forma defendida por Alexy. O que o conceito de **mandamento de otimização** impõe é o que se pode

chamar de ideia regulativa, ou seja, uma ideia que sirva para *guiar a argumentação em um determinado sentido*. Várias podem ser as respostas que satisfaçam as exigências de otimização. Quanto maior o número de variáveis — e de direitos — envolvidos em um caso concreto, maior tenderá a ser a quantidade de respostas que satisfaçam o critério de otimização”. [16](#)

De modo geral, partindo das ideias expostas, podemos **esquematizar** as distinções essenciais entre **regras** e **princípios**:

REGRAS	PRINCÍPIOS
■ dimensão da validade , especificidade e vigência	■ dimensão da importância , peso e valor
■ conflito entre regras (uma das regras em conflito ou será afastada pelo princípio da especialidade, ou será declarada inválida — cláusula de exceção, que também pode ser entendida como “declaração parcial de invalidade”)	■ colisão entre princípios (não haverá declaração de invalidade de qualquer dos princípios em colisão. Diante das condições do caso concreto, um princípio prevalecerá sobre o outro)
■ “tudo ou nada”	■ ponderação, balanceamento, sopesamento entre princípios colidentes
■ mandamentos ou mandados de definição	■ mandamentos ou mandados de otimização

Finalmente, correta a constatação de Barroso ao perceber que mais recentemente e avançando as ideias de Dworkin e os novos desenvolvimentos analíticos trazidos por Alexy, “... já se discute tanto a aplicação do esquema **tudo**

ou nada aos **princípios** como a possibilidade de também as **regras** serem **ponderadas**. Isso porque, como visto, determinados princípios — como o princípio da dignidade da pessoa humana e outros — apresentam um núcleo de sentido ao qual se atribui natureza de regra, aplicável biunivocamente. Por outro lado, há situações em que uma regra, perfeitamente válida em abstrato, poderá gerar uma inconstitucionalidade ao incidir em determinado ambiente, ou, ainda, há hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar...”. [17](#)

■ 3.3. DERROTABILIDADE (*DEFEASIBILITY*) [18](#)

De modo geral, conforme estabelece Humberto Ávila, existem várias **justificativas** para a **obediência às regras**, destacando-se: [19](#)

- “eliminação da controvérsia e da incerteza, e dos custos morais a elas associados”;
- eliminação ou redução da “... arbitrariedade que pode potencialmente surgir no caso de aplicação direta de valores morais”;
- busca para “evitar problemas de coordenação, deliberação e conhecimento”. No tocante à *coordenação*, sem a regra, haveria o risco de cada indivíduo querer defender o seu ponto de vista. Em relação à *deliberação*, inexistindo solução predefinida em determinada regra, observar-se-ia um aumento de custos para soluções casuísticas e individuais. Finalmente, a falta de regra poderia produzir soluções por pessoas que não têm o *conhecimento* técnico de determinada matéria ou área.

Com isso, observa Ávila que “... as regras não devem ser obedecidas somente por serem regras e serem editadas por uma autoridade. Elas **devem ser obedecidas**, de um lado, porque sua **obediência** é **moralmente boa** e, de outro, porque produz efeitos relativos a valores prestigiados pelo próprio ordenamento jurídico, como **segurança**, **paz** e **igualdade**. Ao contrário do que a atual exaltação dos princípios poderia fazer pensar, as regras não são normas

de segunda categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de solução previsível, eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos sociais”.[20](#)

Apesar dessa constatação, muitos autores, conforme já enunciado, começam a reconhecer a **derrotabilidade** (*defeasibility*) das regras, superando o modelo “tudo ou nada” de Dworkin.

A ideia de **derrotabilidade** (Ávila se refere a ela como **superabilidade**), historicamente, vem sendo atribuída a **Hart**, na seguinte passagem: “quando o estudante aprende que na lei inglesa existem condições positivas exigidas para a existência de um contrato válido, ele ainda tem que aprender o que pode derrotar a reivindicação de que há um contrato válido, mesmo quando todas essas condições são satisfeitas”, daí por que “o estudante tem ainda que aprender o que pode seguir as palavras ‘a menos que’, as quais devem acompanhar a indicação dessas condições”.[21](#)

Nesse sentido, Ávila, reconhecendo que as regras não são superáveis com facilidade,[22](#) propõe algumas **condições necessárias**, destacando-se:

■ **requisitos materiais (ou de conteúdo):** a superação da regra pelo caso individual não pode prejudicar a concretização dos valores inerentes à regra. E explica o autor: “... há casos em que a decisão individualizada, ainda que incompatível com a hipótese da regra geral, não prejudica nem a promoção da **finalidade subjacente à regra**, nem a **segurança jurídica** que suporta as regras, em virtude da pouca probabilidade de reaparecimento frequente de situação similar, por dificuldade de ocorrência ou comprovação”;[23](#)

■ **requisitos procedimentais (ou de forma):** a superação de uma regra deve ter **a) justificativa condizente** — devendo haver a “... demonstração de incompatibilidade entre a hipótese da regra e sua finalidade subjacente. É preciso apontar a discrepância entre aquilo que a hipótese da regra estabelece e o que sua finalidade exige”. E, ainda, a “... demonstração de que o afastamento da regra não provocará expressiva insegurança jurídica”. Em outras palavras, a *justiça individual* não poderá afetar substancialmente a *justiça geral*; **b) fundamentação condizente** — as

razões de superação da regra devem ser **exteriorizadas**, para que, assim, possam ser controladas. “A fundamentação deve ser escrita, juridicamente fundamentada e logicamente estruturada”; **c) comprovação condizente** — “... não sendo necessárias, notórias nem presumidas, a ausência do aumento excessivo das controvérsias, da incerteza e da arbitrariedade e a inexistência de problemas de coordenação, altos custos de deliberação e graves problemas de conhecimento devem ser comprovadas por meios de provas adequados, como documentos, perícias ou estatísticas. A mera alegação não pode ser suficiente para superar uma regra”.

Analisando os requisitos propostos por Ávila para a eventual **superação das regras**, concordamos com a crítica apontada por Vasconcellos, no tocante aos requisitos materiais, no sentido de que se poderia pensar em certa **“universalização/generalização das decisões baseadas na derrotabilidade”**, e não que essa generalização pudesse gerar a sugerida insegurança.

Conforme aponta Vasconcellos, “... o requisito material mais importante da derrotabilidade é a **coerência** do julgador ou órgão durante a decisão. (...). Em nome da coerência, o processo de inserção da *exceção* no interior da regra impõe o fenômeno da **universalização**, a partir do qual a decisão singular se torna **paradigmática**, **referência** e **modelo** às ulteriores (posteriores, acrescente-se) decisões de casos similares”.²⁴

CUIDADO: do ponto de vista jurisprudencial, alertamos que o **STF** ainda não utilizou a expressão **derrotabilidade**.

Destacamos, contudo, dois interessantes julgados que utilizaram a ideia para a fundamentação de suas decisões:

■ **TRF1 — EDAMS 5553 — GO 2001.35.00.005553-9 — j. 16.03.2005 — 6.^a Turma, DJ de 18.04.2005** — discutia-se a regra contida no art. 99 da Lei n. 8.112/90, que **assegura** ao servidor estudante (ao seu cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial) que mudar de sede no interesse da administração, na localidade da nova residência ou na mais próxima, **matrícula em instituição de ensino congênere**, em qualquer época, independentemente de vaga (cf. a

discussão sobre o assunto, no presente trabalho, no *item 14.10.2*). Esse entendimento já foi, inclusive, confirmado pelo STF, no julgamento da **ADI 3324**, que destacou a necessidade de ser o estabelecimento de ensino congênere, ou seja, a transferência deverá ser de escola particular para particular e de pública para pública. No caso concreto dos autos, contudo, como não havia na localidade instituição da mesma natureza, o TRF1 entendeu que “... a vedação em causa é ‘**derrotável**’, porquanto o legislador, ao editar o dispositivo em referência, não considerou essa circunstância em sua formulação normativa, de forma que o *princípio do direito constitucional à educação* (Carta Magna, art. 205), bem como o de que as *normas restritivas devem ser interpretadas restritivamente* ‘**derrotam**’ a vedação contida no referido dispositivo legal”;²⁵

■ **Recurso JEF n. 20053500716438826 — TJ/GO:** no caso, discutia-se o direito ao recebimento do *benefício de prestação continuada* previsto no art. 20, § 3.º, da Lei n. 8.742/93, que consiste na garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos (redação dada pela Lei n. 12.435/2011) ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, sendo que se considera incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal *per capita* seja inferior a 1/4 do salário mínimo. No caso concreto, o Juiz **Juliano Taveira Bernardes** utilizou a ideia de **derrotabilidade** para afastar a regra geral, sem que o seu entendimento ferisse, inclusive, o posicionamento do STF, que entende ser o requisito financeiro condição objetiva para o recebimento do benefício. Vejamos:

“EMENTA: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. RENDA *PER CAPITA*. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR A REGRA LEGAL EM FACE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ANTINOMIA EM ABSTRATO VS. ANTINOMIA EM CONCRETO. ‘**DERROTABILIDADE**’ DO § 3.º DO ART. 20 DA LEI 8.742/93.

1. Embora o STF já tenha reconhecido a constitucionalidade em tese do § 3.º do art. 20 da Lei 8.742/93, o requisito da renda mensal *per capita* inferior a 1/4 do salário mínimo, consideradas todas as circunstâncias do caso, pode apresentar antinomia concreta em face de algum princípio constitucional ou

regra implícita deste decorrente.

2. O reconhecimento dessa antinomia concreta gera a ‘derrotabilidade’ (*defeasibility*) da regra legal, mas **não viola** a **autoridade** da decisão do **STF** proferida na **ADI 1.232/DF**.

3. Quando se resolve uma antinomia em abstrato, considera-se a norma desprezada, para todas as demais hipóteses em que a norma se aplicaria porque: (a) inválida (em caso de conflito hierárquico); ou (b) sem vigência (conflito cronológico); ou (c) ineficaz (conflito da especialidade). Diferentemente, a resolução de uma antinomia em concreto não implica qualquer juízo de invalidação da norma que se deixou de aplicar, a qual **segue válida, vigente e eficaz** para se aplicar a outras situações.

4. Não bastasse, a decisão de mérito da ADI 1.232/DF tampouco dispõe de efeitos vinculantes, já que proferida antes da edição da Lei 9.868/99.

5. Comprovados gastos com medicamentos necessários à manutenção da pessoa que necessita do amparo constitucional, deve ser diminuída, em iguais proporções, a base de cálculo da renda mensal *per capita*.

6. Recurso desprovido. Sentença confirmada.”

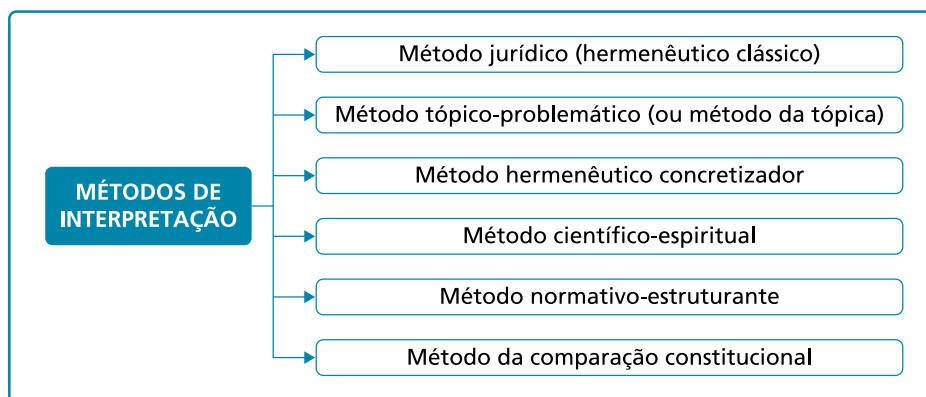
■ 3.4. NORMAS DE SEGUNDO GRAU: POSTULADOS NORMATIVOS

Humberto Ávila, como já apontamos, refere-se à categoria dos **postulados normativos**, que não se confundem com as regras e os princípios.

Segundo afirma, os postulados podem ser qualificados como **metanormas** ou **normas de segundo grau**, instituindo “... critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto da aplicação”.

Assim, podem ser caracterizados como **normas metódicas**, fornecendo “critérios bastante precisos para a aplicação do Direito”, destacando-se os *postulados inespecíficos* (**ponderação**, **concordância prática** e **proibição de excesso**) e os *postulados específicos* (**igualdade**, **razoabilidade** e **proporcionalidade**).²⁷

■ 3.5. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO



Anota Canotilho que “a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de **métodos**, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em critérios ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) diferentes mas, em geral, reciprocamente complementares”.²⁸ Nessa linha, limitar-nos-emos a expor algumas características de cada um dos métodos destacados pelo mestre português.

■ 3.5.1. Método jurídico ou hermenêutico clássico

Para os que se valem desse método, a Constituição deve ser encarada como uma **lei** e, assim, todos os **métodos tradicionais** de hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa, valendo-se dos seguintes elementos de exegese:

- **elemento genético:** busca investigar as origens dos conceitos utilizados pelo legislador;
- **elemento gramatical ou filológico:** também chamado de literal ou semântico, pelo qual a análise deve ser realizada de modo textual e literal;
- **elemento lógico:** procura a harmonia lógica das normas constitucionais;
- **elemento sistemático:** busca a análise do todo;
- **elemento histórico:** analisa o projeto de lei, a sua justificativa, exposição de motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e

psicológicas que resultaram na elaboração da norma;

- **elemento teleológico ou sociológico:** busca a finalidade da norma;

- **elemento popular:** a análise se implementa partindo da participação da massa, dos “corpos intermediários”, dos partidos políticos, sindicatos, valendo-se de instrumentos como o plebiscito, o referendo, o *recall*, o veto popular etc.;

- **elemento doutrinário:** parte da interpretação feita pela doutrina;

- **elemento evolutivo:** segue a linha da mutação constitucional.

Nesse método, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da norma, o seu sentido e, assim, atribui-se grande importância ao texto da norma.

■ 3.5.2. Método tópico-problemático (ou método da tópica)

Por meio desse método, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados.

A Constituição é, assim, um sistema **aberto** de regras e princípios.

■ 3.5.3. Método hermenêutico-concretizador

Diferentemente do método tópico-problemático, que parte do caso concreto para a norma, o método hermenêutico-concretizador parte da Constituição para o problema, destacando-se os seguintes pressupostos interpretativos:

- **pressupostos subjetivos:** o intérprete vale-se de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma;

- **pressupostos objetivos:** o intérprete atua como mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como “pano de fundo” a realidade social;

- **círculo hermenêutico:** é o “movimento de ir e vir” do subjetivo para o

objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma.

O fato de se partir das pré-compreensões do intérprete pode distorcer não somente a realidade, como também o próprio sentido da norma.

■ 3.5.4. Método científico-espiritual

A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da **realidade social** e dos valores subjacentes do texto da Constituição.

Assim, a Constituição deve ser interpretada como algo **dinâmico** e que se **renova constantemente**, no compasso das modificações da vida em sociedade.

Sustenta Inocêncio Mártires Coelho que, segundo o método científico-espiritual,

“... tanto o direito quanto o Estado e a Constituição são vistos como **fenômenos culturais** ou fatos referidos a **valores**, a cuja realização eles servem de instrumento”.[29](#)

■ 3.5.5. Método normativo-estruturante

A doutrina que defende esse método reconhece a inexistência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo.

Isso porque o teor literal da norma (elemento literal da doutrina clássica), que será considerado pelo intérprete, deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social.

A norma terá de ser concretizada não só pela atividade do legislador, mas, também, pela atividade do Judiciário, da administração, do governo etc.

Para Coelho, “em síntese, no dizer do próprio Müller, o teor literal de qualquer prescrição de direito positivo é apenas a ‘ponta do *iceberg*’; todo o resto, talvez a parte mais significativa, que o intérprete-aplicador deve levar em conta para realizar o direito, isso é constituído pela *situação normada*, na feliz expressão de Miguel Reale”.[30](#)

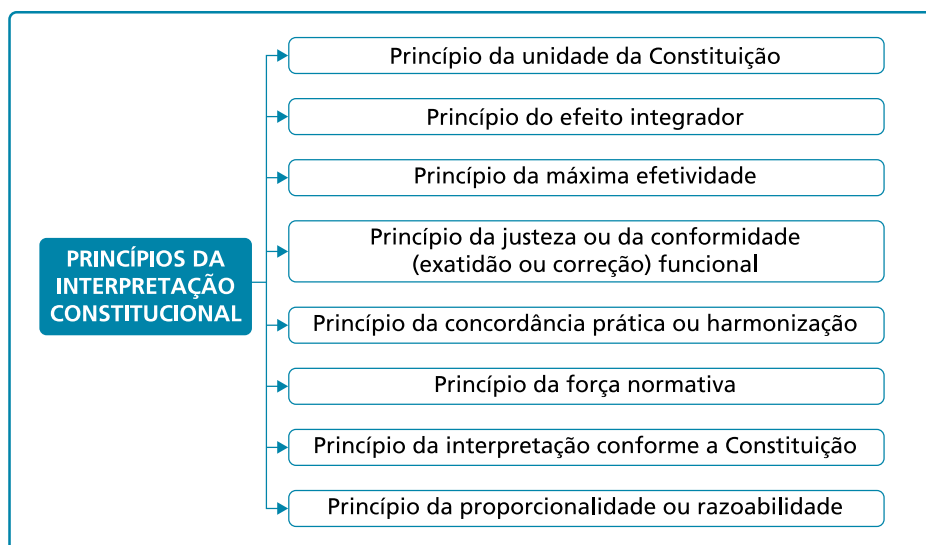
■ 3.5.6. Método da comparação constitucional

A interpretação dos institutos se implementa mediante comparação nos vários ordenamentos.

Estabelece-se, assim, uma comunicação entre as várias Constituições. Partindo dos 4 *métodos* ou elementos desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, histórico e sistemático), Peter Häberle sustenta a **canonização** da comparação constitucional como um *quinto* método de interpretação. [31](#)

■ 3.6. PRINCÍPIOS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Ao lado dos métodos de interpretação, a doutrina [32](#) estabelece alguns **princípios específicos de interpretação** e que podem ser assim esquematizados:



■ 3.6.1. Princípio da unidade da Constituição

A Constituição deve ser sempre interpretada em sua globalidade, como um todo, e, assim, as aparentes antinomias deverão ser afastadas.

As normas deverão ser vistas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios.

Anota Canotilho que, “como ‘ponto de orientação’, ‘guia de discussão’ e ‘factor hermenêutico de decisão’, o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a Constituição na sua **globalidade** e a procurar **harmonizar os espaços de tensão** (...) existentes entre as normas constitucionais a concretizar (ex.: princípio do Estado de Direito e princípio democrático, princípio unitário e princípio da autonomia regional e local)”. [33](#)

■ 3.6.2. Princípio do efeito integrador

Muitas vezes associado ao princípio da unidade, conforme ensina Canotilho, “... na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Como tópico argumentativo, o princípio do efeito integrador não assenta numa concepção integracionista de Estado e da sociedade (conducente a reducionismos, autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalismos políticos), antes arranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções pluralisticamente integradoras”. [34](#)

■ 3.6.3. Princípio da máxima efetividade

Também chamado de princípio da **eficiência** ou da **interpretação efetiva**, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social.

Segundo Canotilho, “é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas programáticas (THOMA), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)”. [35](#)

■ 3.6.4. Princípio da justeza ou da conformidade (exatidão ou correção)

funcional

O intérprete máximo da Constituição, no caso brasileiro o STF, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer a *força normativa* da Constituição, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como é o caso da separação de poderes, no sentido de preservação do Estado de Direito.

O seu intérprete final “... não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido (EHMKE)”.[36](#)

Nos momentos de crise, acima de tudo, as relações entre o Parlamento, o Executivo e a Corte Constitucional deverão ser pautadas pela irrestrita **fidelidade** e **adequação** à **Constituição**.

■ **3.6.5. Princípio da concordância prática ou harmonização**

Partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando, assim, evitar o sacrifício (total) de um princípio em relação a outro em choque. O fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre os princípios.

Nas palavras de Canotilho, “o campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido até agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionalmente protegidos). Subjacente a este princípio está a ideia do igual valor dos bens constitucionais (e não uma diferença de hierarquia) que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes bens”.[37](#)

■ **3.6.6. Princípio da força normativa**

Os aplicadores da Constituição, ao solucionar conflitos, devem conferir a máxima efetividade às normas constitucionais.

Assim, de acordo com Canotilho, “na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da Constituição (normativa), contribuem para uma eficácia ótima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam a ‘atualização’ normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia e permanência”. [38](#)

Nesse sentido, como anota Gilmar Mendes, “sem desprezar o significado dos fatores históricos, políticos e sociais para a força normativa da Constituição, confere Hesse peculiar realce à chamada *vontade da Constituição* (*Wille zur Verfassung*). A Constituição, ensina Hesse, transforma-se em força ativa se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se fizerem presentes, na consciência geral — particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional —, não só a vontade de poder (*Wille zur Macht*), mas também a vontade de Constituição (*Wille zur Verfassung*)”. [39](#)

■ 3.6.7. Princípio da interpretação conforme a Constituição

Diante de **normas plurissignificativas** ou **polissêmicas** (que possuem mais de uma interpretação), deve-se preferir a exegese que mais se aproxime da Constituição e, portanto, que não seja contrária ao texto constitucional, daí surgirem várias dimensões a serem consideradas, seja pela doutrina, [40](#) seja pela jurisprudência, destacando-se que a interpretação conforme será implementada pelo Judiciário e, em última instância, de maneira final, pela Suprema Corte:

■ **prevalência da Constituição:** deve-se preferir a interpretação não contrária à Constituição;

■ **conservação de normas:** percebendo o intérprete que uma lei pode ser interpretada em conformidade com a Constituição, ele deve assim aplicá-la

para evitar a sua não continuidade;

■ **exclusão da interpretação *contra legem***: o intérprete não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma para obter a sua concordância com a Constituição;

■ **espaço de interpretação**: só se admite a interpretação conforme a Constituição se existir um espaço de decisão e, dentre as várias a que se chegar, deverá ser aplicada aquela em conformidade com a Constituição;

■ **rejeição ou não aplicação de normas inconstitucionais**: uma vez realizada a interpretação da norma, pelos vários métodos, se o juiz chegar a um resultado contrário à Constituição, em realidade, deverá declarar a inconstitucionalidade da norma, proibindo a sua correção contra a Constituição;

■ **intérprete não pode atuar como legislador positivo**: não se aceita a interpretação conforme a Constituição quando, pelo processo de hermenêutica, se obtiver uma regra nova e distinta daquela objetivada pelo legislador e com ela contraditória, em seu sentido literal ou objetivo. Deve-se, portanto, afastar qualquer interpretação em contradição com os objetivos pretendidos pelo legislador. Avançando, se a vontade do legislador violar a Constituição, confira interessante discussão dentro da ideia de **decisões manipulativas** (item 3.7.2).

■ 3.6.8. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade

Ao expor a doutrina de Karl Larenz,⁴¹ Coelho esclarece: “utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das *restrições* de direitos — muito embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na *concessão* de poderes, privilégios ou benefícios —, o princípio da *proporcionalidade* ou da *razoabilidade*, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positividade jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para

todo o ordenamento jurídico”.[42](#)

Trata-se de princípio extremamente importante, em especial na situação de colisão entre valores constitucionalizados.

Como parâmetro, podemos destacar a necessidade de preenchimento de 3 importantes elementos:

- **necessidade:** por alguns denominada **exigibilidade**, a adoção da medida que possa restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra menos gravosa;

- **adequação:** também chamado de **pertinência** ou **idoneidade**, quer significar que o meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido;

- **proporcionalidade em sentido estrito:** sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, em termos de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outros valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima efetividade e mínima restrição.

Finalmente, lembramos importantes **dispositivos normativos** que explicitamente adotam o princípio da proporcionalidade (que, no plano constitucional, não está enunciado de modo formal e categórico, mas decorre do devido processo legal, em sua acepção **substantiva** — art. 5.º, LIV):

- **Art. 2.º, VI, da Lei n. 9.784/99:** “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, **razoabilidade**, **proporcionalidade**, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) VI — **adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público**”.

- **Art. 156 do CPP:** “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I — ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas

urgentes e relevantes, observando a **necessidade**, **adequação** e **proporcionalidade** da medida” (incluído pela Lei n. 11.690/2008).

■ **Art. 282, I e II, do CPP:** “As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I — **necessidade** para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II — **adequação** da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (redação e inclusões pela Lei n. 12.403/2011).

■ **Art. 438, §§ 1.º e 2.º, do CPP:** “A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1.º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. § 2.º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da **proporcionalidade** e da **razoabilidade**” (redação e inclusões pela Lei n. 11.689/2008).

■ 3.7. LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Diante das premissas de interpretação postas, surge a necessidade de se estabelecerem parâmetros objetivos e critérios firmes de interpretação, à luz da ideia de **certeza** e **segurança jurídica**.

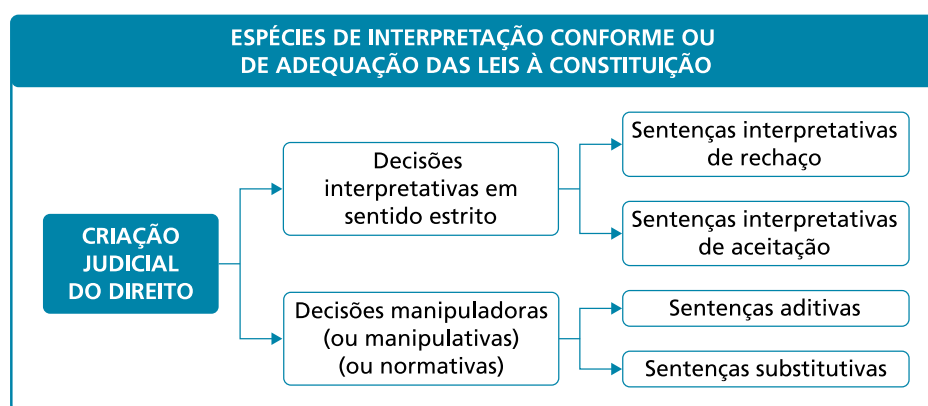
Não se pode desconhecer a realidade atual e inevitável de, muitas vezes, **criação judicial do direito**, já que entre a declaração de nulidade absoluta total da lei ou ato normativo e o não conhecimento da ação, em termos de segurança, preferem-se as **decisões interpretativas com efeitos modificativos ou corretivos**.

Nesse sentido, o **texto constitucional** apresenta-se como porto seguro para os necessários limites da interpretação, destacando-se a **interpretação**

conforme a Constituição como verdadeira **técnica de decisão**.

Nas palavras de Inocêncio Mártires Coelho, a atual realidade “... parece condenar ao esquecimento a concepção kelseniana de *legislador negativo*, tantas têm sido as decisões das Cortes Constitucionais — *e.g.* as diversas espécies de sentenças *normativas* — por via das quais, a pretexto de *otimizar e/ou realizar* a Constituição, esses supertribunais assumem nítida postura legislativa, criando normas de caráter geral e vinculante, como atestam a jurisprudência nacional e a estrangeira, esta em maior expressão”.⁴³

Estamos diante de verdadeira **atividade legislativa heterônoma**, destacando-se, segundo **Riccardo Guastini**,⁴⁴ as seguintes espécies de *interpretação conforme* ou de *adequação* das leis à Constituição:



■ 3.7.1. Decisões interpretativas em sentido estrito

■ 3.7.1.1. *Sentença interpretativa de rechaço*

Diante de duas possíveis interpretações que determinado ato normativo possa ter, por meio das **sentenças interpretativas de rechaço**, a Corte Constitucional adota aquela que se conforma à Constituição, **repudiando** qualquer outra que contrarie o texto constitucional.

Assim, o enunciado “permanece válido, mas só poderá ser interpretado de maneira conforme à Constituição, o que significa dizer que, implicitamente, e sob pena de vir a considerá-la nula, a Corte proíbe que se dê ao citado

dispositivo interpretação contrária à Constituição”.[45](#)

■ 3.7.1.2. *Sentença interpretativa de aceitação*

Por sua vez, nas **sentenças interpretativas de aceitação**, a Corte Constitucional **anula** decisão tomada pela magistratura comum (instâncias ordinárias), que adotou interpretações ofensivas à Constituição.

Não se “... anula o dispositivo *mal interpretado*, mas apenas uma das suas interpretações, dizendo que esse preceito é inconstitucional se interpretado de modo contrário à Constituição ou *na parte em que expressa uma norma inconstitucional*. Também nesse caso, prossegue Guastini, o preceito questionado continua válido, mas a norma extraída da sua interpretação **inconstitucional** é anulada em caráter definitivo e com eficácia *erga omnes*”.[46](#)

■ 3.7.2. *Decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)*

As **decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)** são originárias da doutrina e jurisprudência italianas (*decisioni manipolative*).

Conforme observou Coelho, as decisões **manipuladoras** (ou **manipulativas**) (ou **normativas**) podem ser caracterizadas como “... sentenças de aceitação em que a Corte Constitucional não se limita a declarar a inconstitucionalidade das normas que lhe são submetidas, mas, agindo como legislador positivo, modifica (= manipula) diretamente o ordenamento jurídico, adicionando-lhe ou substituindo-lhe normas, a pretexto ou com o propósito de adequá-lo à Constituição. Daí a existência das chamadas sentenças *aditivas* e *substitutivas*, como subespécies das decisões normativas ou manipuladoras”.[47](#)

■ 3.7.2.1. *Sentenças aditivas (ou sentenças manipulativas de efeito aditivo). Declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo ou aditivo*

No entendimento de Mendes, pela **sentença aditiva** (ou “manipulativa de efeito aditivo”), “... a Corte Constitucional declara inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa, mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência”.[48](#)

A sentença aditiva pode ser justificada, por exemplo, em razão da não observância do **princípio da isonomia**, notadamente nas situações em que a lei concede certo benefício ou tratamento a determinadas pessoas, mas exclui outras que se enquadrariam na mesma situação.

Nessas hipóteses, o Tribunal Constitucional declara inconstitucional a norma na parte em que trata desigualmente os iguais, sem qualquer razoabilidade e/ou nexo de causalidade.

Assim, a decisão se mostra **aditiva**, já que a Corte, ao decidir, “cria uma norma autônoma”, estendendo aos excluídos o benefício.

Estamos em face daquilo que Canotilho denominou **declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo (aditivo)**, na medida em que a sentença do Tribunal “alarga o âmbito normativo de um preceito, declarando inconstitucional a disposição na ‘parte em que não prevê’, contempla uma ‘exceção’ ou impõe uma ‘condição’ a certas situações que deveria prever (**sentenças aditivas**)”.[49](#)

As sentenças aditivas já são realidades na Suprema Corte brasileira, destacando-se os seguintes julgados, conforme anotou Mendes:[50](#)

■ **ADPF 54 — antecipação terapêutica do parto em casos de gravidez de feto anencefálico:** como destacamos no *item 14.10.1.3*, o STF, em 12.04.2012, por maioria, ao julgar a ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde — CNTS, produziu **decisão manipulativa com eficácia aditiva**, atuando como **legislador positivo**, já que, ao dar interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 128 do CP, acrescentou mais uma excludente de punibilidade ao crime de aborto.

■ **MI 670/ES, MI 708/DF, MI 712/PA — direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, da CF/88):** o STF, ao julgar os

referidos mandados de injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado do Espírito Santo — SINDIPOL, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa — SINTEM e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará — SINJEP, reconheceu **(sentença aditiva)** que fosse garantido o direito de greve a todo servidor público, aplicando-se, no que couber, a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada.

■ **RMS 22.307 — reajuste para os servidores civis não contemplado por lei que o concedeu aos militares:** o STF entendeu, de modo aditivo, que o reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares, pelas Leis n. 8.662/93 e n. 8.627/93, deveria ser estendido também aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. **Cuidado:** essa previsão de que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-ia sempre na mesma data era estabelecida no art. 37, X, da CF/88, **antes de sua modificação pela EC n. 19/98**, que acabou com a correlação.

■ **ADIs 1.105 e 1.127 — Estatuto da Advocacia:** o STF, ao dar interpretação conforme a Constituição a diversos preceitos da Lei n. 8.906/94, adicionou-lhe conteúdo normativo, conforme apontamos no *item 12.5* deste estudo.

■ **MS 26.602, 26.603 e 26.604 — fidelidade partidária:** como estudaremos no *item 18.5*, o STF entendeu que a fidelidade partidária é princípio constitucional, e, por isso, aquele candidato eleito pelo **sistema proporcional** que mudar de partido (*transferência de legenda*) sem motivo justificado perderá o cargo eletivo (entendimento que não se aplica para os eleitos pelo sistema majoritário — **ADI 5.081**, j. 27.05.2015).

■ **PET 3.388 — demarcação Raposa Serra do Sol:** o STF reconheceu o modelo **contínuo** de demarcação da terra indígena e, para tanto, determinou diversas **condições**, em caráter marcadamente aditivo (cf. *item 19.10.7.2*).

Além dos exemplos trazidos por Gilmar Mendes, podemos destacar julgados envolvendo o direito fundamental dos trabalhadores ao **aviso prévio proporcional ao tempo de serviço**, sendo no mínimo de trinta dias, *nos termos da lei (art. 7.º, XXI)*.

Trata-se de norma de **eficácia limitada** que só veio a ser regulamentada mais de 20 anos após a promulgação da CF/88, no caso, nos termos da **Lei n. 12.506, de 11.10.2011**.

O STF, no julgamento de diversos MIs, *antes do advento da norma*, julgou procedente o pedido para reconhecer a mora e garantir a concretização do direito previsto na Constituição e para o caso concreto (**MI 943, 1.010, 1.074 e 1.090**, j. 22.06.2011).

Diante de indecisão sobre qual parâmetro adotar (e, assim, estabelecer o efeito **aditivo**), até porque, diferentemente do direito de greve supracitado, não havia nenhum critério normativo preestabelecido a ser observado, houve suspensão do julgamento.

Em seguida, com censurável atraso, o Congresso Nacional aprovou a citada Lei n. 12.506/2011, que não retroagiu e, assim, não resolveu a situação dos trabalhadores demitidos antes de sua vigência e que *ajuizaram mandado de injunção, pendente de julgamento*.

O STF determinou a utilização dos critérios e padrões normativos estabelecidos na referida lei (**sentença aditiva**, portanto), adotando, como anotou o Min. Gilmar Mendes, um “posicionamento menos invasivo às competências do Congresso Nacional e perfeitamente cabível para o deslinde das ações mandamentais” (fls. 47 do acórdão, j. 06.02.2013). [51](#)

■ 3.7.2.2. **Sentenças substitutivas (declaração de inconstitucionalidade com efeito substitutivo)**

Na lição de Branco, ao editar **sentenças substitutivas**, “... a Corte declara a inconstitucionalidade de um preceito *na parte em que expressa certa norma em lugar de outras*, substancialmente distinta, que dele deveria constar para que

fosse compatível com a Constituição. Atuando dessa forma, a Corte não apenas **anula** a norma impugnada, como também a **substitui por outra**, essencialmente diferente, criada pelo próprio tribunal, o que implica a produção heterônoma de atos legislativos ou de um *direito judicial*, como o denomina Prieto Sanchís, para quem tais normas já nascem enfermas porque desprovidas de fundamento democrático. Apesar dessa ressalva, esse mesmo jurista pondera que, embora os juízes não ostentem uma *legitimidade de origem*, de que desfruta o Parlamento por força de eleições periódicas, é de se reconhecer à magistratura uma *legitimidade de exercício*, de resto passível de controle pela crítica do seu comportamento”. [52](#)

Como exemplo, podemos citar a liminar concedida na **ADI 2332** (Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.09.2001, Plenário, *DJ* de 02.04.2004) contra dispositivos da MP 2183-56, que, alterando o Decreto-lei n. 3.365/41, **estabeleceu**, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, que a **incidência** de juros compensatórios será de até **6% ao ano** sobre o **valor da diferença eventualmente apurada**, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

De acordo com a decisão do STF, a limitação de 6% ao ano viola o entendimento adotado na Súmula 618/STF (“na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano”). Ainda, a fixação da base de cálculo como sendo “o valor da diferença eventualmente apurada” também viola o princípio constitucional do direito à **justa indenização**.

Assim, a taxa de juros de 6% ao ano foi declarada inconstitucional pelo STF e **substituída** pela de 12%. No tocante à base de cálculo dos juros compensatórios contida no introduzido *caput* do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, para que não se ferisse o princípio constitucional do prévio e justo preço, foi dada interpretação conforme a Constituição, para se ter como constitucional (aqui a **substituição**) o entendimento de que essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e

o valor do bem fixado na sentença (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

■ 3.7.3. Lacuna constitucional e o “pensamento jurídico do possível” na jurisprudência do STF

O denominado “**pensamento jurídico do possível**” foi destacado no julgamento de embargos infringentes opostos pelo PGR contra acórdão proferido pelo STF na **ADI 1.289**, no qual se discutia o preenchimento da regra do “quinto constitucional” no âmbito do TRT.

Como veremos (*itens 11.7 e 11.8.4.2*), o art. 115, I, da CF/88 prescreve que os TRTs serão compostos por 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT com mais de 10 anos de efetivo exercício, **observado o disposto no art. 94**.

Referido art. 94 estabelece um procedimento rígido, ao prescrever que o órgão de classe elabore uma lista sêxtupla com nomes que preencham os requisitos do art. 94. Em seguida, o Tribunal escolhe 3 dentre os 6 indicados, e o Executivo escolhe 1 da lista tríplice e o nomeia.

O texto é claro ao definir que a lista tríplice será formada dentro do universo dos 6 nomes indicados e que a escolha final do Executivo se dará dentre os 3 escolhidos pelo Tribunal. Ou seja, se a lista elaborada pelo órgão de classe for de 5 nomes, a escolha de 3 ficará prejudicada, pois o Tribunal não terá mais o universo de 6.

Isso posto, surgiu um problema. No caso concreto, em se tratando de vaga a ser preenchida por membro do Ministério Público, não havia membros suficientes com mais de 10 anos de efetivo exercício.

A Corte deparou-se com inegável **lacuna constitucional**: a Carta não dispôs sobre a hipótese excepcional de faltarem membros no Ministério Público que preenchessem os requisitos constitucionais.

Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes lembrou o trabalho de **Gustavo Zagrebelsky** sobre o **direito dúctil**, especialmente diante das características das

sociedades pluralistas atuais, marcadas pela **diversidade de grupos sociais, interesses e ideologias** e, em razão das circunstâncias do caso concreto, concluiu pela adoção do denominado **“pensamento do possível”**.

Destaca Mendes: “... parece dominar a aspiração a algo que é conceitualmente impossível, porém altamente desejável na prática: a não prevalência de um só valor e de um só princípio, senão a salvaguarda de vários simultaneamente. O imperativo teórico da não contradição — válido para a *scientia juris* — não deveria obstaculizar a atividade própria da *jurisprudencia* de intentar realizar positivamente a **‘concordância prática’ das diversidades, e inclusive das contradições que, ainda que assim se apresentem na teoria, nem por isso deixam de ser desejáveis na prática**. ‘Positivamente’: não, portanto mediante a simples amputação de potencialidades constitucionais, senão principalmente mediante prudentes soluções acumulativas, combinatórias, compensatórias, que conduzam os princípios constitucionais a um **desenvolvimento conjunto** e não a um declínio conjunto (Zagrebelsky, *El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia*. Trad. de Marina Gascón. 3. ed. Edt. Trotta S.A., Madrid, 1999. p. 16 — grifamos)”.

Continua Gilmar Mendes lembrando **Peter Häberle** como talvez o mais expressivo defensor da ideia de “ser o **‘pensamento jurídico do possível’ expressão, consequência, pressuposto e limite para uma interpretação constitucional aberta** (Häberle, P. Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken, in: *Die Verfassung des Pluralismus*, Königstein/TS, 1980, p. 9 — grifamos)”.

Ainda, Mendes fala de uma **“teoria constitucional de alternativas”** na medida em que, como sustentado por Häberle, **“o pensamento do possível é o pensamento em alternativas**. Deve estar aberto para terceiras ou quartas possibilidades, assim como para compromissos. Pensamento do possível é pensamento indagativo (*fragendes Denken*). Na *res publica* existe um *ethos* jurídico específico do pensamento em alternativa, que contempla a **realidade** e a **necessidade**, sem se deixar dominar por elas. O **pensamento do possível** ou o **pensamento pluralista de alternativas** abre suas perspectivas para ‘novas’

realidades, para o fato de que a realidade de hoje pode corrigir a de ontem, especialmente a adaptação às necessidades do tempo de uma visão normativa, sem que se considere o novo como o melhor” (Häberle, *Die Verfassung des Pluralismus*, cit., p. 3 — grifamos)”.

E conclui Mendes: “... valendo-nos da lição de Scheuner citada por Häberle, se quiser preservar **força regulatória** em uma **sociedade pluralista**, a **Constituição** não pode ser vista como texto acabado ou definitivo, mas sim como **‘projeto’ (‘Entwurf’) em contínuo desenvolvimento** (Häberle, *Die Verfassung des Pluralismus*, cit., p. 4 — grifamos)”.

Pedimos vênia, então, para transcrever a ementa do julgado que reconheceu, na linha do voto do Min. Gilmar Mendes, a teoria do **pensamento do possível**:

“EMENTA: (...). Cargos vagos de juízes do TRT. Composição de lista. Requisitos dos arts. 94 e 115 da Constituição: quinto constitucional e lista sêxtupla. Ato normativo que **menos se distancia do sistema constitucional**, ao assegurar aos órgãos participantes do processo a margem de escolha necessária. **Salvaguarda simultânea de princípios constitucionais em lugar da prevalência de um sobre o outro. Interpretação constitucional aberta** que tem como pressuposto e limite o chamado **‘pensamento jurídico do possível’**. Lacuna constitucional. Embargos acolhidos para que seja reformado o acórdão e julgada improcedente a ADI 1.289, declarando-se a constitucionalidade da norma impugnada” (**ADI 1.289-EI**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.04.2003, Plenário, *DJ* de 27.02.2004).

Finalmente, podemos lembrar outros exemplos de aplicação pela Corte do **pensamento do possível**, como a técnica da **lei “ainda constitucional”** em relação ao prazo em dobro para a defensoria pública no processo penal (cf. *item 6.7.1.6*).

■ 3.7.4. Críticas ao “pan-principiologismo” e a realidade de uma inegável “Supremocracia”

Parte da doutrina vem tecendo (severas) críticas à exacerbação dos (pseudo)princípios, ou seja, a criação de princípios de acordo com o “sentire” ou

a vontade de cada julgador, de modo arbitrário, em decisão “solipsista” (seguindo a orientação pessoal de cada intérprete) e em violação à Constituição, o que pode levar à discricionariedade e a um inaceitável e antidemocrático *decisionismo* (julgamento discricionário e sem fundamentação, surgindo decisões contraditórias a fragilizar a isonomia) — tendo sido essa problemática-constatação denominada “**pan-principiologismo**”.⁵³

As decisões, sem dúvida, devem encontrar sustentação na Constituição, que, como afirmamos (*item 3.7*), deve ser o **porto seguro** para os necessários limites da interpretação, evitando-se, assim, os riscos de uma **ditadura do Poder Judiciário**.

As regras devem ser prestigiadas, mas, diante de colisão e impossibilidade de convivência, os princípios deverão ser destacados (aliás, inimaginável o sistema sem os princípios). As soluções devem ser com base nos verdadeiros princípios, que encontram fundamento histórico na luta por uma Constituição democrática (essa a grande dificuldade, qual seja, a identificação desses princípios). Devem ser evitados os pseudoprincípios, que serviriam, muitas vezes, de álibis teóricos para as decisões sem fundamentação firme.

A solução proposta por **Humberto Ávila**, já lançada, mostra-se bastante equilibrada. Conforme sustenta, a *interpretação* e a *aplicação* de **princípios** e **regras** dar-se-ão com base nos **postulados normativos inespecíficos**, quais sejam, a **ponderação** (atribuindo-se pesos), a **concordância prática** e a **proibição de excesso** (garantindo a manutenção de um mínimo de eficácia dos direitos fundamentais), e *específicos*, destacando-se o postulado da **igualdade**, o da **razoabilidade** e o da **proporcionalidade**.⁵⁴

Essa preocupação ganha relevância com a posição que a Suprema Corte adquiriu após a Constituição de 1988 e, mais recentemente, com a Reforma do Poder Judiciário, tudo em razão da inegável **hiperconstitucionalização** do pós-Segunda Grande Guerra na reconstrução do Estado Democrático de Direito.

Sem dúvida, esse modelo fez surgir aquilo que a doutrina denominou “**Supremocracia**” e que tem um duplo sentido: **a)** autoridade que o STF assume em relação às instâncias inferiores, já que, no modelo brasileiro, adquire

o papel de intérprete final da Constituição; **b)** a partir da CF/88, o deslocamento do STF para o centro do arranjo político, observando-se uma inegável expansão de sua autoridade em detrimento dos demais poderes. [55](#)

Conforme anotou Vieira, “esta posição institucional vem sendo paulatinamente ocupada de forma substantiva, em face a enorme tarefa de guardar tão extensa Constituição. A ampliação dos instrumentos ofertados para a jurisdição constitucional tem levado o Supremo não apenas a exercer uma espécie de poder moderador, mas também de responsável por emitir a última palavra sobre inúmeras questões de natureza substantiva, ora validando e legitimando uma decisão dos órgãos representativos, outras vezes substituindo as escolhas majoritárias”.

Essa expansão da autoridade do STF deve-se às ampliadas atribuições de tribunal constitucional, de foro especializado e originário de várias matérias (veja o julgamento da AP 470 — mensalão, para se ter um exemplo), bem como de tribunal de recursos de última instância. [56](#)

Sem dúvida, parece ter razão Vieira ao propor uma **autocontenção** da atuação da Corte, que passaria a julgar de modo mais qualitativo os grandes temas inseridos na Constituição, o que provocaria o seu fortalecimento e, por consequência, o fortalecimento das instâncias inferiores.

■ 3.8. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS

Conforme anotou o Ministro Celso de Mello, em interessante julgado, a **teoria dos poderes implícitos** decorre de doutrina que, tendo como precedente o célebre caso *McCULLOCH* v. *MARYLAND* (1819), da Suprema Corte dos Estados Unidos, estabelece: “... a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos” (MS 26.547-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.05.2007, *DJ* de 29.05.2007).

Podemos acrescentar que os meios implicitamente decorrentes das atribuições

estabelecidas de modo explícito devem passar por uma análise de **razoabilidade** e **proporcionalidade**.

Encontramos alguns precedentes na jurisprudência pátria.

Em um primeiro caso, o STF reconhece o **poder implícito** de concessão de **medidas cautelares** pelo TCU no exercício de suas atribuições explicitamente fixadas no art. 71 da CF/88 (MS 26.547-MC/DF).

Em outro precedente, o STF admite a possibilidade de o TJ estadual conhecer e julgar **reclamação** para a preservação de sua competência e a autoridade de suas decisões. Entendeu a Corte que a **reclamação**, situada no âmbito do exercício do **direito de petição** (art. 5.º, XXXIV, “a”) e, tendo em vista o **princípio da simetria** e o da **efetividade das decisões judiciais**, dentro de uma ideia de **poderes implícitos**, poderia ser **apreciada pelo tribunal estadual**, superando, assim, antiga jurisprudência que a fixava como privativa do STF (ADI 2.212) (cf. ADI 2.480, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007, *DJ* de 15.06.2007).

Em outro caso interessante e bastante polêmico, com base na **teoria dos poderes implícitos**, a 2.ª Turma do STF, ao analisar a temática dos **poderes investigatórios do MP**, entendeu que a denúncia pode ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo próprio *Parquet*, não havendo necessidade de prévio inquérito policial (**RE 535.478**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.10.2008, *DJE* de 21.11.2008. Nesse sentido: **HC 89.837**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2009, 2.ª T., *Inf.* 564/STF e **RHC 83.492**, j. 16.12.2010). [57](#)

Enfrentando o tema, o **Pleno** do STF, em momento seguinte, afirmou a seguinte tese: “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei n. 8.906/94, art. 7.º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Estado

Democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição” (RE 593.727, j. 14.05.2015 — pendente de publicação).

■ 3.9. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA A INTERPRETAÇÃO PLURALISTA E “PROCEDIMENTAL” DA CONSTITUIÇÃO

SOCIEDADE FECHADA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO	SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO
■ Sociedade fechada ■ Intérpretes jurídicos vinculados às corporações	■ Interpretação constitucional pela e para a sociedade aberta ■ Sociedade pluralista ■ Intérpretes jurídicos (convivem com os intérpretes da sociedade aberta e pluralista) ■ Órgãos estatais ■ Potências públicas ■ Cidadãos ■ Grupos ■ Sistema público e opinião pública ■ Participantes materiais do processo social

fechado com numerus clausus de intérpretes da Constituição	■ “Constituição e realidade constitucional” — incorporação das ciências sociais, teorias jurídico-funcionais e métodos de interpretação voltados para o atendimento do interesse público e do bem-estar geral ■ Subsistência da jurisdição constitucional — juízes e tribunais, normalmente a última palavra na interpretação ■ Direito de participação democrática ■ Democratização da interpretação constitucional ■ Intérpretes constitucionais em sentido lato (amplo) ■ Maior legitimidade das decisões judiciais em razão da pluralização do debate
--	--

Conforme anotou Gilmar Mendes ao lembrar as lições de Peter Häberle, “não existe norma jurídica, senão **norma jurídica interpretada** (...), [58](#) ressaltando que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública (...). [59](#) Assim, se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, tem-se, necessariamente, de indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional sobre as forças ativas da *Law in public action*”. [60](#)

Daí propor Häberle que se supere o modelo de interpretação de uma *sociedade fechada* (nas mãos de juízes e em procedimentos formalizados) para a ideia de uma **sociedade aberta dos intérpretes da Constituição**, vale dizer, uma interpretação **pluralista** e **democrática**.

Ao afirmar que a interpretação não mais deve ficar confinada dentro de uma *sociedade fechada*, Häberle propõe a ideia de que a interpretação não possa ficar restrita aos órgãos estatais, mas que deve ser **aberta** para todos os que “vivem” a norma (a Constituição), sendo, assim, esses destinatários, legítimos intérpretes, em um interessante **processo de revisão** da metodologia jurídica

tradicional de interpretação.

Häberle observa que, dentro de um conceito mais amplo de hermenêutica, “**cidadãos e grupos, órgãos estatais, o sistema público e a opinião pública** (...) representam **forças produtivas de interpretação** (...); eles são intérpretes constitucionais em **sentido lato**, atuando nitidamente, pelo menos, como **pré-intérpretes** (...). **Subsiste** sempre a responsabilidade da **jurisdição constitucional**, que fornece, em geral, a última palavra sobre a interpretação (...). Se se quiser, tem-se aqui uma democratização da interpretação constitucional”.⁶¹

Nesse sentido, **quanto mais pluralista for a sociedade, mais abertos serão os critérios de interpretação**.

No direito brasileiro, destacamos a figura do *amicus curiae*⁶² e das **audiências públicas**, tema que será retomado no *item 6.7.1.16* deste estudo.

Desde que haja necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o **relator** requisitar outras, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.⁶³

Além da atribuição fixada ao relator (art. 21, XVII, do *RISTF*), nos termos do art. 13, XVII, do *RI/STF*, compete ao Presidente do STF convocar **audiência pública** para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal, o que nos permite afirmar que a previsão não se resume aos processos de ADI, ADC e ADPF (cf. arts. 9.º, § 1.º, e 20, § 1.º, da Lei n. 9.868/99 e art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99).

Nesse particular, interessante ressaltar a **primeira audiência pública** realizada no Brasil, em processo jurisdicional de controle concentrado de constitucionalidade, na data de **20.04.2007**, em cumprimento ao preceituado no art. 9.º, § 1.º, da Lei n. 9.868/99 (portanto, quase 8 anos após a sua previsão na referida lei).

n. 9.868/99 (portanto, quase 8 anos após a sua previsão na referida lei).

Tratava-se da **ADI 3.510**, proposta pelo PGR, contra a utilização de células-tronco de embriões humanos em pesquisas e terapias. Conforme aprofundamos no *item 14.10.1.2*, o STF entendeu, por 6 x 5, que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida, nem mesmo a dignidade da pessoa humana, julgando, assim, improcedente a ação.

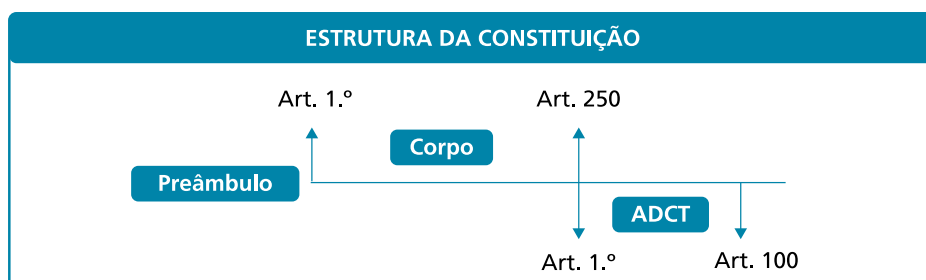
Outras audiências públicas foram verificadas, destacando-se: [64](#)

REFERÊNCIA	TEMA	DATA DESIGNADA
■ ADI 3.510	■ pesquisas com células-tronco embrionárias	■ 20.04.2007
■ ADPF 101	■ importação de pneus usados	■ 27.06.2008
■ ADPF 54	■ interrupção de gravidez: feto anencefálico	■ 26 e 28.08 e 04 e 16.09.2008
■ AgR nas SL 47 e 64; STA 36, 185, 211 e 278; SS 2.361, 2.944, 3.345 e 3.355	■ judicialização da saúde pública e, em especial, a possibilidade de decisões jurisdicionais obrigarem o Estado a fornecer tratamentos e medicamentos	■ 27 a 29.04 e 04, 06 e 07.05.2009
■ ADPF 186 e RE 597.285	■ políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior	■ 03 a 05.03.2010
■ ADI 4.103	■ lei seca: proibição da venda de bebidas alcoólicas nas proximidades das rodovias	■ 07 e 14.05.2012

■ ADI 3.937	■ proibição do uso do amianto	■ 24 e 31.08.2012
■ ADIs 4.679, 4.756 e 4.747	■ novo marco regulatório para a TV por assinatura no Brasil	■ 18 e 25.02.2013
■ RE 627.189	■ campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia	■ 06 a 08.03.2013
■ RE 586.224	■ queimadas de canaviais	■ 22.04.2013
■ RE 641.320	■ regime prisional	■ 27 e 28.05.2013
■ ADI 4.650	■ financiamento de campanhas eleitorais	■ 17 e 24.06.2013
■ ADI 4.815	■ biografias não autorizadas	■ 21 e 22.11.2013
■ ADIs 5.037 e 5.035	■ programa “Mais Médicos”	■ 25 e 26.11.2013
■ ADIs 5.062 e 5.065	■ alterações no marco regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil	■ 17.03.2014
■ RE 581.488	■ internação hospitalar com “diferença de classe” no Sistema Único de Saúde	■ 26.05.2014

Enfim, parece extremamente importante essa perspectiva de uma **sociedade aberta dos intérpretes da Constituição** para que as decisões judiciais sejam dotadas, cada vez mais, de maior legitimidade e, por que não dizer, justiça.

■ 3.10. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO [65](#)



■ 3.10.1. Preâmbulo

■ 3.10.1.1. Esquematização

Estruturalmente, a CF/88 contém um **preâmbulo**, **nove títulos (corpo)** e o **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)**.

Nas provas de concursos, tem sido muito comum o examinador exigir o conhecimento da literalidade do preâmbulo, bem como os direitos e preceitos estabelecidos ou nele referidos. Assim, procuramos, abaixo, esquematizar a leitura para facilitar a memorização:

PREÂMBULO	
■ Nós,	
■ representantes do povo brasileiro,	
■ reunidos em Assembleia Nacional Constituinte	

■ para instituir um Estado Democrático ,
■ destinado a assegurar o exercício
■ dos direitos sociais e individuais ,
■ a liberdade ,
■ a segurança ,
■ o bem-estar ,
■ o desenvolvimento ,
■ a igualdade
■ e a justiça
■ como valores supremos
■ de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos ,
■ fundada na harmonia social e comprometida , na ordem interna e internacional ,
■ com a solução pacífica das controvérsias ,
■ promulgamos,
■ sob a proteção de Deus ,

■ **3.10.1.2. Qual a natureza jurídica do preâmbulo? Tem ele relevância jurídica?**

Três são as posições apontadas pela doutrina e sistematizadas por Jorge Miranda: a) **tese da irrelevância jurídica**: o preâmbulo situa-se no domínio da política, sem relevância jurídica; b) **tese da plena eficácia**: tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais, sendo, porém, apresentado de forma não articulada; c) **tese da relevância jurídica indireta**: ponto intermediário entre as duas, já que, muito embora participe “das características jurídicas da Constituição”, não deve ser confundido com o articulado.

Jorge Miranda ensina que o preâmbulo, “... proclamação mais ou menos solene, mais ou menos significativa, anteposta ao articulado constitucional, não é componente necessário de qualquer Constituição, mas tão somente um elemento natural de Constituições feitas em momentos de ruptura histórica ou de grande transformação político social”. Assim, conclui Miranda, o preâmbulo “não cria direitos ou deveres” e “não há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo”.⁶⁶

Nesse sentido, o Ministro Carlos Velloso, Relator da ADI 2.076, após interessante estudo, conclui que “o preâmbulo ... não se situa no âmbito do Direito, mas **no domínio da política**, refletindo posição **ideológica** do constituinte (...). **Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica**. O preâmbulo não constitui norma central da Constituição, de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro. O que acontece é que o preâmbulo contém, de regra, proclamação ou exortação no sentido dos princípios inscritos na Carta (...). Esses princípios sim, **inscritos na Constituição**, constituem normas centrais de reprodução obrigatória, ou que não pode a Constituição do Estado-membro dispor de forma contrária, dado que, reproduzidos, **ou não**, na Constituição estadual, incidirão na ordem local...”.⁶⁷

Por todo o exposto, podemos estabelecer, adotando a **tese da irrelevância jurídica**, que o preâmbulo da Constituição não é norma de reprodução obrigatória nos Estados, nem pode servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade.

■ **3.10.1.3. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios? Referida previsão enfraquece a laicidade do Estado brasileiro?**

Não.

Como se sabe, desde o advento da República (Dec. n. 119-A, de 07.01.1890), existe total separação entre o Estado e a Igreja, sendo o Brasil um país **leigo, laico** ou **não confessional**, não existindo, portanto, nenhuma religião oficial da República Federativa do Brasil.⁶⁸

Laicidade não se confunde com **laicismo**. Laicidade significa neutralidade religiosa por parte do Estado. Laicismo, uma atitude de intolerância e hostilidade estatal em relação às religiões. Portanto, a **laicidade** é marca da República Federativa do Brasil, e não o laicismo, mantendo-se o Estado brasileiro em posição de neutralidade axiológica, mostrando-se indiferente ao conteúdo das ideias religiosas (cf. voto do Min. Celso de Mello na ADPF 54 — *anencefalia*).

Todas as Constituições pátrias, exceto as de 1891 e 1937, invocaram a “*proteção de Deus*” quando promulgadas, exprimindo, assim, inegável símbolo de religiosidade.⁶⁹

Em âmbito estadual essa realidade se repetiu, com exceção, em sua redação original, da Constituição do Estado do **Acre, que não continha, em um primeiro momento, a referida expressão.**⁷⁰ Tal omissão foi objeto de questionamento no STF pelo Partido Social Liberal. O STF, definindo a questão, além de estabelecer e declarar a **irrelevância jurídica do preâmbulo**, assinalou que a invocação da “*proteção de Deus*” **não é norma de reprodução obrigatória** na Constituição estadual, não tendo força normativa (**ADI 2.076-AC**, Rel. Min. Carlos Velloso).

O STF também confirmou que a invocação a Deus no preâmbulo **não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro**, que, inclusive, nos termos do **art. 5.º, VI**, declara ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre-exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias.

Ainda, o **art. 5.º, VIII**, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Finalmente, o **art. 19, I**, determina, tendo em vista a inexistência de religião oficial, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a **colaboração de interesse público**.

Como exemplo de *colaboração de interesse público*, podemos citar a **decretação de ponto facultativo** para os servidores municipais de São Paulo quando, em 11 de maio de 2007, o **Papa Bento XVI** esteve em São Paulo para celebrar a missa de **canonização de Frei Galvão**.

Interessante, ainda, a crítica de José Afonso da Silva: “um Estado leigo não deveria invocar Deus em sua Constituição. Mas a verdade também é que o **sentimento religioso** do povo brasileiro, se não impõe tal invocação, a **justifica**. Por outro lado, para os **religiosos** ela é **importante**. Para os **ateus**, há de ser **indiferente**. Logo, não há por que condená-la. Razão forte a justifica: o *sentimento popular de quem provém o poder constituinte*”.⁷¹

Apesar dessa crítica apresentada por Silva, Branco chega a afirmar que “o Estado brasileiro não é confessional, mas **tampouco é ateu**, como se deduz do preâmbulo da Constituição, que invoca a proteção de Deus. Por isso, admite, ainda que sob a forma de disciplina de matrícula facultativa, o ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental (CF, art. 210, § 1.º), permitindo, assim, o ensino da doutrina de uma dada religião para os alunos interessados.

Admite, igualmente, que o casamento religioso produza efeitos civis, na forma do disposto em lei (CF, art. 226, §§ 1.º e 2.º)”.[72](#)

Nesse sentido, Daniel Sarmiento também estabelece que “**Estado laico não significa Estado ateu**, pois o ateísmo não deixa de ser uma concepção religiosa. Na verdade, o **Estado laico** é aquele que mantém uma postura de **neutralidade** e **independência** em relação a todas as concepções religiosas, em respeito ao **pluralismo** existente em sua sociedade”.[73](#)

Esse posicionamento doutrinário, de não se confundir **Estado laico** com **Estado ateu**, encontra reconhecimento no voto do Min. Marco Aurélio no julgamento da **ADPF 54** (*anencefalia*), ao afirmar que o Brasil é um Estado secular tolerante, ou seja, “o Estado não é religioso, **tampouco é ateu**. O Estado é simplesmente **neutro**”.

Assim, continua, “a crença religiosa e espiritual — ou a ausência dela, o ateísmo — serve precipuamente para ditar a **conduta** e a **vida privada** do indivíduo que a possui ou não a possui. **Paixões religiosas de toda ordem não de ser colocadas à parte na condução do Estado**. Não podem a fé e as orientações morais dela decorrentes ser impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja” (fls. 44).

Do mesmo entendimento, com precisão, Daniel Sarmiento, ao afirmar que “... as razões religiosas são válidas na esfera da consciência de cada um, mas não podem ser o fundamento dos atos estatais”.[74](#)

Por todo o exposto, podemos sustentar que o **preâmbulo não tem relevância jurídica, não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória**, servindo, apenas, como **norte interpretativo das normas constitucionais**. Por essas características e por não constituir norma central, a invocação à divindade **não é de reprodução obrigatória** nos preâmbulos das Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios. Conforme visto, o Brasil é um país **leigo, laico** ou **não confessional, lembrando que Estado laico não significa Estado ateu**.

■ 3.10.2. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)

■ 3.10.2.1. Apontamentos gerais sobre o ADCT

Disposições Constitucionais Transitórias são encontradas nas Constituições brasileiras anteriores, exceto na primeira, de 1824.

Nas Constituições de 1891, 1934 e 1946, assim como na atual, de 1988, o **ADCT** aparece como **ato destacado**, possuindo, respectivamente, 8, 26 e 36 artigos, sendo que, na redação original da CF/88, promulgada em 5 de outubro, o texto continha **70** artigos, contando, atualmente, com **100**, em razão de reformas constitucionais.

Nos textos autoritários de 1937, 1967 e na EC n. 1/69, as disposições transitórias foram apresentadas em conjunto, no mesmo título, com as *disposições finais ou gerais*.

Outra característica interessante dos textos nos quais o **ADCT** se apresenta de **forma destacada** (inclusive com promulgação autônoma em relação às disposições do corpo)⁷⁵ é a particular **técnica redacional** de se iniciar uma **nova numeração dos artigos**, bem como a inexistência de divisão em *títulos*, *capítulos*, *seções* ou *subseções*.

Conforme observou Raul Machado Horta, “os temas são tratados indistintamente, sem a preocupação de ordenação, unidade e sistematização. É o terreno do depósito residual, da miscelânea e da mistura normativa. O traço que aproxima as normas heterogêneas é a temporariedade e a transitoriedade”.⁷⁶

■ 3.10.2.2. Finalidade do ADCT

A finalidade do ADCT é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, instituído pela manifestação do poder constituinte originário, providenciando a **acomodação** e a **transição** do antigo e do novo direito edificado.

Segundo Barroso, “destinam-se as normas dessa natureza a auxiliar na transição de uma ordem jurídica para outra, procurando neutralizar os efeitos nocivos desse confronto, no tempo, entre regras de igual hierarquia —

Constituição nova *versus* Constituição velha — e de hierarquia diversa — Constituição nova *versus* ordem ordinária preexistente”,[77](#) interligando-se, portanto, nesse aspecto, com o instituto da *recepção*.

Observa-se, assim, por consequência, que, historicamente, algumas constituições, em outros países, **não estabeleceram regras de transição**, sobretudo quando o novo regime apresentava-se totalmente desvinculado da organização político-jurídica que até então vigorava, rompendo-se de modo revolucionário.

Como exemplo, podemos identificar a *Constituição norte-americana de 1787*, que estabeleceu a federação (superando o imperialismo britânico e extinguindo o modelo confederativo), bem como a *francesa de 1791*, que, abolindo o feudalismo e o antigo regime, consagrou “(...) a Monarquia Constitucional, a representação política fundada na soberania nacional e os direitos naturais e imprescritíveis do homem: a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”.[78](#)

Nesse sentido, destacou Raul Machado Horta: “as Constituições vinculadas **às transformações profundas da ordem social, política e econômica** não se preocupam com a inclusão de normas ou disposições transitórias em seu texto.”[79](#) Voltadas para a edificação de nova Sociedade, as Constituições revolucionárias, que demoliram e substituíram os fundamentos do antigo regime, não se interessam pelas normas de acomodação e de transição entre o direito anterior e o novo direito. A teleologia do constitucionalismo revolucionário repele acomodações que embaraçam a construção do novo Direito e a edificação criadora de nova estrutura social, política e econômica”.[80](#)

■ 3.10.2.3. *Classificação das disposições do ADCT*

Analisando o seu conteúdo durante o ano inicial de sua vigência, **Raul Machado Horta** identificou as seguintes categorias normativas:[81](#)

- **normas exauridas:** aquelas que já desapareceram, em virtude da realização da condição ou do ato nela previstos, como, por exemplo, os

arts. 1.º; 4.º, § 4.º; 15 etc.;

■ **normas dependentes de legislação e de execução:** arts. 10, § 1.º; 12, § 1.º; 14, §§ 1.º, 2.º e 4.º etc.;

■ **normas dotadas de duração temporária expressa:** art. 40, que manteve, por 25 anos, a partir da promulgação da Constituição, a Zona Franca de Manaus (prazo esse acrescido de 10 anos pela EC n. 42/2003, nos termos do art. 92 do ADCT e, findo esse prazo, acrescido de mais 50 anos, nos termos da EC n. 83/2014, nos termos do art. 92-A, também do ADCT); art. 42, também alterado por emenda, modificando as regras de transição;

■ **normas de recepção:** art. 34, § 5.º; art. 66 etc.;

■ **normas sobre benefícios e direitos:** arts. 53 e 54, que asseguraram direitos;[82](#)

■ **normas com prazos constitucionais ultrapassados:** nessa classificação, o autor identificou, à época (no primeiro ano de vigência do ADCT), todos os artigos que dependiam de legislação para sua implementação, como o art. 29, § 1.º, que fixava prazo para o encaminhamento de projeto de lei complementar dispoendo sobre a organização e o funcionamento da AGU, e o art. 48 do ADCT, que estabelecia prazo para que o Congresso Nacional elaborasse o *Código de Defesa do Consumidor*. Muitos dispositivos, como os citados, já foram regulamentados.

Por sua vez, **Barroso**,[83](#) identificando espécies distintas de disposições transitórias, estabeleceu três categorias:

■ **disposições transitórias propriamente ditas:** são as disposições típicas que regulam de modo transitório determinadas relações, estando sujeitas a condição resolutiva ou termo. Como exemplo, o autor lembra o art. 10, § 1.º,[84](#) e o art. 23, *caput*;[85](#)

■ **disposições de efeitos instantâneos e definitivos:** essas disposições não aguardam uma condição ou um termo, operando imediatamente ou no prazo estabelecido. Nesse sentido, podemos citar o art. 13, *caput*, do ADCT, que criou o Estado do Tocantins, ou o art. 15, que extinguiu o

Território Federal de Fernando de Noronha, reincorporando a sua área ao Estado de Pernambuco;

■ **disposições de efeitos diferidos:** são aquelas que “sustam a operatividade da norma constitucional por prazo determinado ou até a ocorrência de um determinado evento”. Como exemplo, o autor menciona o art. 5.º, *caput*, do ADCT, que determinou a não aplicação do disposto no art. 16 e das regras do art. 77 do corpo da Constituição às eleições previstas para 15.11.1988.

■ 3.10.2.4. *O natural exaurimento das normas do ADCT e o seu desvirtuamento*

Vimos que as disposições transitórias, como o próprio nome já sinaliza, exercem o papel de **acomodação** e **transição** do ordenamento jurídico anterior com a nova ordem constitucional.

Por natureza, portanto, diante de sua **eficácia temporária** (essa a ideia das disposições de transição), após produzirem os seus efeitos, ou diante do advento da condição ou termo estabelecidos, **esgotam-se**, tornando-se normas de **eficácia exaurida**.

Nesse momento, aponta José Afonso da Silva, a norma do ADCT que se esgotou “... não é mais norma jurídica, mas **simples proposição sintática**, com **valor meramente histórico**”, não mais se restabelecendo. [86](#)

Daí, Raul Machado Horta conclui que “**norma permanente** nas Disposições Transitórias é **norma anômala**. Foi dessa categoria o conhecido art. 180 [87](#) da Carta de 1937, que, prevendo competência transitória do Presidente da República — ‘enquanto não se reunir o Parlamento Nacional’ —, como a condição não se verificou na vigência da Carta de 1937, o art. 180 tornou-se regra permanente, para fundamentar a pletórica atividade legislativa do Presidente da República na via dos Decretos-leis”. [88](#)

Essa sistemática, contudo, vem sendo desvirtuada pelo constituinte reformador, que, por vezes, introduziu, por emenda ao ADCT, normas **permanentes, sem qualquer conteúdo de direito intertemporal** e **sem**

qualquer conexão com o momento de transição, em total *atecnia legislativa*, como, por exemplo, o seu art. 96 (acrescentado pela EC n. 57/2008), que, de modo inconstitucional (e, por que não dizer, imoral), convalidou a criação de municípios em total violação ao art. 18, § 4.º, da CF/88 (cf. *item 6.7.4.9*).

■ 3.10.2.5. Qual a natureza jurídica das disposições do ADCT?

O ADCT, como o nome já induz (Ato das Disposições **Constitucionais** Transitórias), tem **natureza jurídica de norma constitucional** e poderá, portanto, trazer exceções às regras colocadas no corpo da Constituição. Assim como no corpo encontramos regras (por exemplo, tratamento igual entre brasileiro nato e naturalizado, art. 12, § 2.º) e exceções a essas regras (por exemplo, art. 12, § 3.º, I, que reserva o cargo de Presidente da República somente para brasileiros natos), também o ADCT poderá excepcionar regras gerais do corpo, [89](#) por apresentar a mesma natureza jurídica delas.

Dessa forma, **em virtude de sua natureza constitucional**, a alteração das normas do ADCT ou o acréscimo de novas regras dependerão da manifestação do *poder constituinte derivado reformador*, ou seja, necessariamente por meio de **emendas constitucionais** que, por sua vez, deverão observar os **limites ao poder de reforma** (cf. abaixo, *item 3.10.2.6*), sendo que essas disposições novas estabelecidas por emenda serão suscetíveis ao controle de constitucionalidade. Também, em razão de sua natureza jurídica, as disposições do ADCT servirão de **parâmetro** ou **paradigma de confronto** para a análise da constitucionalidade dos demais atos normativos. Nesse sentido, decidiu a Corte:

“EMENTA: (...). Os postulados que informam a teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o necessário substrato doutrinário assentam-se na premissa fundamental de que o sistema de direito positivo, além de caracterizar uma **unidade institucional**, constitui um **complexo de normas que devem manter entre si um vínculo de essencial coerência**. O *Ato das Disposições Transitórias*, promulgado em 1988 pelo legislador constituinte,

qualifica-se, juridicamente, como um **estatuto de índole constitucional**. A estrutura normativa que nele se acha consubstanciada ostenta, em consequência, a **rigidez** peculiar às regras inscritas no texto básico da Lei Fundamental da República. Disso decorre o reconhecimento de que **inexistem, entre as normas inscritas no ADCT e os preceitos constantes da Carta Política, quaisquer desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia ou à prevalência de sua autoridade**. Situam-se, ambos, no mais elevado grau de positividade jurídica, impondo-se, no plano do ordenamento estatal, enquanto categorias normativas subordinantes, à observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos que integram o aparelho de Estado” (RE 160.486, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.1994, 1.^a Turma, DJ de 09.06.1995. No mesmo sentido: RE 215.107-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.11.2006, 2.^a T., DJ de 02.02.2007).

■ 3.10.2.6. As disposições do ADCT estão imunes ao poder de reforma?

Diante da constatação de diversas emendas ao ADCT (lembre que, originalmente, ele foi promulgado com 70 artigos, contendo, atualmente, **100**), temos de analisar a possibilidade ou não de reformas das disposições transitórias em razão da manifestação do *poder constituinte derivado reformador*. Ou seja, poderiam, de fato, as normas do ADCT ter sofrido alterações (modificações ou acréscimos) por emenda?

Entendemos que se a norma de transição já se tiver **exaurido**, nesse caso específico, não pareceria razoável o Constituinte reformador *modificar* o sentido da transição já concretizado conforme estabelecido pelo *poder constituinte originário*, até porque, como se afirmou, nessa hipótese, a norma de transição estará **esgotada**.

Por outro lado, se o comando de transição não se tiver realizado e a disposição produzido os seus efeitos, entendemos possível a sua alteração, desde que sejam observados, naturalmente, os **princípios intangíveis** e os **limites ao poder de reforma**, explícitos e implícitos (cf. *item 9.14.1*).

Assim, um direito fundamental estabelecido no ADCT, por exemplo, o art.

68, que reconhece, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos, não poderia ser subtraído por meio de reforma (emenda constitucional) por violar o limite material da **cláusula pétrea** contida no art. 60, § 4.º, IV.

Nesses casos, citando os exemplos dos arts. 8.º (concessão de anistia) e 19 (concessão de estabilidade no serviço público) do ADCT, pelos quais se **atribuiu um regime vantajoso a um grupo concreto de destinatários**, consoante observa Branco, “... pode-se reconhecer que o constituinte originário quis investir beneficiários certos em direitos determinados, de tal sorte que, se o constituinte de reforma lhes subtraísse ou diminuísse a vantagem, estaria perpetrando, senão um ataque à cláusula pétrea da segurança jurídica ou do direito adquirido, certamente que uma fraude ao constituinte originário”.⁹⁰

Por outro lado, a EC n. 2/92, que antecipou a data do plebiscito de que trata o art. 2.º do ADCT, do dia 07.09.1993 para o dia 21.04.1993, foi considerada constitucional pelo STF. Dessa forma, no referido *leading case*, a **Corte** passou a **admitir**, explicitamente, a **alteração de disposições do ADCT por emenda** desde que, é claro, fossem respeitados os limites ao poder de reforma.

Em seu voto, o Min. Moreira Alves, Relator, **reconhecendo o caráter constitucional das normas do ADCT**, não admitiu qualquer natureza de imutabilidade em razão de sua transitoriedade, **reconhecendo-se**, nesses termos, **a possibilidade de reforma**, desde que, é claro, como se disse, fossem observados os limites ao poder de reforma. Vejamos:

“(...) a transitoriedade em si mesma não torna impossível a alteração de norma constitucional dessa natureza. Com efeito, se é possível alterar-se, por emenda, a regra da parte permanente para estender-se a todos, e sem limitações, o que a exceção transitória outorgava a alguns com limitações; se é possível criar-se exceção permanente à regra também permanente; é **absolutamente ilógico pretender-se que a exceção transitória, por causa da sua transitoriedade, seja imutável, inclusive para restringir-se ou dilargar-se o período da transitoriedade**” (ADI 829, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14.04.1993, Plenário, DJ de 16.09.1994).

■ 3.11. QUESTÕES

■ 3.11.1. Hermenêutica

1. (Analista Judiciário/STJ — Área Administrativa — CESPE/UnB/2008) (...) Julgue o item a seguir:

Para a moderna teoria constitucional, que define a constituição como um regime aberto de regras e princípios, estes, por sua flexibilidade e abstração, mesmo quando jurídicos, não podem ser considerados como normas constitucionais, mas apenas como normas programáticas, representando uma pauta de valores a ser seguida pelo legislador na edição de novas regras.

2. (Acadepol/2007/MG) Podemos entender por mutação constitucional:

- a) Que ela consiste na interpretação constitucional evolutiva.
- b) Que ela pressupõe alguma modificação significativa no texto formal da Constituição.
- c) Que pode ser mais limitada (emenda) ou mais extensa (revisão).
- d) Que ela depende, necessariamente, da identificação de um caso de repristinação constitucional.

3. (TCE-PR — Analista de Controle — Área Jurídica — FCC/2011) Quando a interpretação de uma Constituição escrita se altera em decorrência da mudança dos valores e do modo de compreensão de uma sociedade, mesmo sem qualquer alteração formalmente realizada, no texto constitucional, pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, está-se diante de uma:

- a) interpretação histórica;
- b) integração normativa;
- c) desconstitucionalização;
- d) mutação constitucional;
- e) hermenêutica geracional.

4. (Promotor de Justiça/SE — CESPE/UnB/2010 — adaptada pelo autor) Assinale verdadeiro ou falso a respeito dos conceitos de mutação constitucional.

Tratando-se de mutação constitucional, o texto da Constituição permanece inalterado, e alteram-se apenas o significado e o sentido interpretativo de determinada norma

constitucional.

5. (XXXII MP/RJ — 2011) No que se refere à interpretação constitucional, o processo informal de alteração da Constituição que possibilita modificar o sentido de norma constitucional originária, sem alterar o seu texto, é:

- a) interpretação constitucional elástica;
- b) interpretação constitucional flexível;
- c) interpretação conforme a Constituição;
- d) mutação constitucional;
- e) método da desconstitucionalização das normas constitucionais.

6. (Analista — MP/SE — Direito — FCC/2010) O processo formal de mudança das Constituições rígidas, por meio da atuação do poder constituinte derivado, com a aprovação de emendas constitucionais, segundo os procedimentos estabelecidos na própria Constituição pelo legislador constituinte originário, é próprio:

- a) da revisão constitucional e da mutação constitucional.
- b) da mutação constitucional e da reforma constitucional.
- c) da reforma constitucional e da revisão constitucional.
- d) da mutação constitucional e do poder constituinte derivado decorrente.
- e) do poder constituinte derivado reformador e da mutação constitucional.

7. (ANATEL — Analista Administrativo — Direito — CESPE/UnB/2006) (...) julgue o item a seguir:

Denomina-se mutação constitucional o processo informal de revisão, atualização ou transição da Constituição sem que haja mudança do texto constitucional.

8. (Defensor Público/PI — CESPE/UnB — 2009) Relativamente à mutação constitucional e aos princípios de interpretação constitucional, assinale a opção correta:

- a) A mutação constitucional não se pode dar por via de interpretação, mas apenas por via legislativa, quando, por ato normativo primário, procura-se modificar a interpretação que tenha sido dada a alguma norma constitucional.
- b) Em constituições rígidas como a CF, a mutação constitucional se manifesta por meio da reforma constitucional, procedimento previsto no próprio texto constitucional disciplinando o modo pelo qual se deve dar sua alteração.

- c) De acordo com o princípio da unidade da CF, as normas constitucionais devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios que não comporta hierarquia, impondo ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contradições eventualmente existentes entre elas.
- d) O princípio da máxima efetividade significa que, entre interpretações possíveis das normas infraconstitucionais, os aplicadores da CF devem prestigiar aquela que consagre sua constitucionalidade e que tenha mais afinidade com os valores e fins constitucionais.
- e) O princípio da supremacia constitucional, mediante o qual nenhuma lei ou ato normativo poderá subsistir validamente se for incompatível com a CF, tem uma dimensão material, mas não formal. Nesse sentido, o descumprimento de preceitos constitucionais de natureza formal não permite a fiscalização judicial da validade do ato, resolvendo-se pelos métodos de controle parlamentar ou administrativo.

9. (25.º Concurso Procurador da República — MPF/2011) É correto afirmar que:

- a) A ponderação de interesses é técnica que busca equacionar as colisões entre princípios constitucionais através da demarcação dos respectivos âmbitos de proteção, de modo a evitar que normas divergentes incidam concomitantemente sobre a mesma hipótese fática.
- b) O Poder Judiciário deve interpretar os tratados internacionais de direitos humanos à luz da Constituição Federal, mas não o contrário, pois se assim não fosse, subverter-se-ia a hierarquia das fontes normativas e o princípio da supremacia da Constituição.
- c) A mutação constitucional consiste na alteração da jurisprudência do STF sobre algum tema de índole constitucional, sem que haja mudança formal no Texto Magno.
- d) São intérpretes da Constituição não apenas os órgãos do Poder Judiciário, como também os demais poderes políticos, além dos múltiplos atores presentes na sociedade civil, que, em seus debates travados na esfera pública, participam da tarefa de atribuição de sentido às normas constitucionais.

10. (PROC./MP/MG/2007) No entendimento de doutrinadores, NÃO é considerado, dentre outros, como princípio e regra interpretativa das normas constitucionais,

- a) a unidade da Constituição — interpretação de maneira a evitar contradições entre as normas constitucionais.
- b) o efeito integrador — primazia aos critérios favorecedores da integração política e social.
- c) a concordância prática ou a harmonização — coordenação e combinação dos bens

jurídicos em conflito.

- d) a força normativa da Constituição — adoção de interpretação que garanta maior eficácia e permanência das normas constitucionais.
- e) a adoção da contradição dos princípios — os preceitos exigem uma interpretação explícita, excluindo-se a implícita.

11. (PROC./LEG./CAM./SP/2007) Leia o seguinte texto:

“[A Constituição] não é uma escritura imobiliária que determina precisamente os limites de seu objeto; ao contrário, é um documento que anuncia os princípios fundamentais fazendo uso de valores e deixando para as pessoas encarregadas de interpretá-la e aplicá-la um espaço amplo para o exercício de julgamentos normativos.” (Laurence Tribe; Michael Dorf. *Hermenêutica constitucional*, 2007.)

Assinale a alternativa que corresponde à correta interpretação do texto.

- a) O texto se refere à interpretação constitucional, consagrando o princípio da unidade constitucional, demonstrando que os dispositivos constitucionais são parte de um sistema maior e formam um todo lógico e teleológico, impedindo que haja interpretação isolada de dispositivos.
- b) Trata-se de texto que se refere à importância da interpretação constitucional, já que os textos das constituições apresentam uma ampla margem interpretativa, pois as constituições possuem em seu texto termos polissêmicos, fundados em valores e princípios, necessitando, portanto, da atividade interpretativa.
- c) Mais do que tratar de princípios de interpretação dos dispositivos constitucionais em si, o texto trata do princípio da supremacia constitucional, pelo qual os atos normativos estatais infraconstitucionais devem estar sempre em conformidade com as previsões constitucionais, sob pena de inconstitucionalidade.
- d) O texto enuncia o princípio da máxima efetividade, princípio da eficiência ou ainda da interpretação efetiva, o qual impõe ao intérprete constitucional que busque, ainda que nos limites do texto, sem alterá-lo, a interpretação que maior eficácia dê ao dispositivo, já que a Constituição não possui termos ou locuções inúteis.
- e) É clara a alusão no texto ao princípio da interpretação conforme a Constituição. Este princípio interpretativo, normalmente inserido no âmbito de atuação das Cortes Constitucionais, define a possibilidade e o âmbito de aplicação das normas, na medida em que estas sejam ou não compatíveis com o texto constitucional, pautando-se pela aplicação dos dispositivos infraconstitucionais sempre que seja possível a

compatibilização destes com a Constituição Federal.

12. (JUIZ/TJ-PR/2006) Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A interpretação conforme a Constituição, com ou sem redução de texto, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tem efeito vinculante e eficácia contra todos.
- b) Interpretação conforme a Constituição é uma técnica de controle de constitucionalidade que encontra o limite de sua utilização no âmbito das possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa harmônica com a Constituição.
- c) A interpretação conforme a Constituição pressupõe uma Constituição rígida e, por consequência, o princípio da hierarquia das normas constitucionais perante o ordenamento jurídico, somada ao princípio da presunção de constitucionalidade.
- d) A técnica de interpretação conforme a Constituição não pode ser utilizada nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, sob o risco de se efetivar dupla declaração de inconstitucionalidade.

13. (TJ/Sergipe/2004) Considerando a moderna hermenêutica constitucional e o papel do Poder Judiciário no desenvolvimento do direito, julgue o item que se segue.

A interpretação conforme a Constituição, como técnica alternativa de decisão no controle abstrato de constitucionalidade, permite à Corte, sem invalidar o texto da norma, restringir-lhe o alcance, com efeito vinculante.

14. (MP/GO/2004) “Utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direitos — muito embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na concessão de poderes, privilégios ou benefícios (...) em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico”. Este texto refere-se a quais princípios da interpretação constitucional?

- a) correção funcional/máxima efetividade;
- b) proporcionalidade/razoabilidade;
- c) unidade/força normativa;
- d) eficácia integradora/interpretação conforme a Constituição.

15. (AGU/Procurador Federal/2004) Quanto ao conceito e à classificação das constituições e das normas constitucionais, à hermenêutica constitucional, às normas programáticas e ao preâmbulo na Constituição da República de 1988 e, ainda, acerca do histórico das disposições constitucionais transitórias, julgue o item seguinte.

O método de interpretação constitucional denominado hermenêutico-concretizador pressupõe a pré-compreensão do conteúdo da norma a concretizar e a compreensão do problema concreto a resolver, havendo, nesse método, a primazia do problema sobre a norma, em razão da própria natureza da estrutura normativo-material da norma constitucional.

16. (TRF-5/2004) Assinale certo ou errado:

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias. Por isso, já se admitiu a declaração de inconstitucionalidade de determinadas normas em face de outras normas de maior precedência hierárquica.

17. (Analista ANATEL/2004) Assinale certo ou errado:

O princípio de interpretação da Constituição segundo o qual, na solução de problemas jurídico-constitucionais, deve-se dar primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política, denomina-se princípio da concordância prática ou da harmonização.

18. (Analista ANATEL/2004) Assinale certo ou errado:

A chamada interpretação conforme a Constituição somente é viável quando a norma constitucional apresentar vários significados, uns compatíveis com a Constituição, que, por isso, devem ser preferidos pelo intérprete, e outros com ela inconciliáveis.

19. (TRF-5/2005) Julgue o item seguinte, acerca da teoria da Constituição

Conforme assentado pelo STF, havendo confronto entre normas constitucionais originárias, a solução do caso concreto não pode ser encontrada no âmbito do controle de constitucionalidade, mas pode ser dada por critérios hermenêuticos, inclusive pela ponderação de valores.

20. (AGU-Proc. Federal/2007 — CESPE/UnB) Assinale certo ou errado:

O princípio da unidade da CF, como princípio interpretativo, prevê que esta deve ser interpretada de forma a se evitarem contradições, antinomias ou antagonismos entre

suas normas.

21. (AGU-Proc. Federal/2007 — CESPE/UnB) Assinale certo ou errado:

Não existe relação hierárquica fixa entre os diversos critérios de interpretação da CF, pois todos os métodos conhecidos conduzem sempre a um resultado possível, nunca a um resultado que seja o unicamente correto. Essa pluralidade de métodos se converte em veículo da liberdade do juiz, mas essa liberdade é objetivamente vinculada, pois não pode o intérprete partir de resultados preconcebidos e, na tentativa de legitimá-los, moldar a norma aos seus preconceitos, mediante a utilização de uma pseudoargumentação.

22. (DP DF/2006 — CESPE/UnB) Assinale certo ou errado:

A generalidade, a abstração e a capacidade de expansão dos princípios constitucionais permitem ao intérprete larga discricionariedade, que favorece o subjetivismo voluntarista dos sentimentos pessoais e das conveniências políticas na aplicação das normas constitucionais.

23. (DP DF/2006 — CESPE/UnB) Assinale certo ou errado:

Entre as modernas formas de interpretação constitucional existentes, às vezes também denominadas técnicas de decisão, destacam-se a declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade e a mutação constitucional, a declaração de inconstitucionalidade com apelo ao legislador e, principalmente, a interpretação conforme a Constituição.

24. (TRT 24.^a Região/MS/2007) Dados os seguintes enunciados:

- I. A interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas.
- II. Os órgãos encarregados da interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta, altere ou perturbe o esquema organizatório-funcional estabelecido pelo legislador constituinte originário.
- III. Os bens jurídicos em conflito deverão estar coordenados e combinados de forma a evitar o sacrifício total de um (uns) em relação a outro(s).
- IV. Entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais.
- V. A uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia se lhe

conceda.

VI. Na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade política.

Relacione-os com o princípio/regra interpretativa de norma constitucional:

- (A) Unidade da Constituição.
- (B) Efeito Integrador.
- (C) Máxima Efetividade ou Eficiência.
- (D) Justeza ou Conformidade Funcional.
- (E) Concordância Prática ou Harmonização.
- (F) Força Normativa da Constituição.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Unidade da Constituição; Efeito Integrador; Máxima Efetividade ou Eficiência; Justeza ou Conformidade Funcional; Concordância Prática ou Harmonização; Força Normativa da Constituição.
- b) Força Normativa da Constituição; Unidade da Constituição; Concordância Prática ou Harmonização; Justeza ou Conformidade Funcional; Máxima Efetividade ou Eficiência; Efeito Integrador.
- c) Unidade da Constituição; Justeza ou Conformidade Funcional; Concordância Prática ou Harmonização; Força Normativa da Constituição; Máxima Efetividade ou Eficiência; Efeito Integrador.
- d) Concordância Prática ou Harmonização; Justeza ou Conformidade Funcional; Máxima Efetividade ou Eficiência; Unidade da Constituição; Força Normativa da Constituição; Efeito Integrador.
- e) Justeza ou Conformidade Funcional; Efeito Integrador; Força Normativa da Constituição; Concordância Prática ou Harmonização; Unidade da Constituição; Máxima Efetividade ou Eficiência.

25. (DF/MS/VUNESP-2008) Considerando a doutrina dominante do direito constitucional, analise as seguintes afirmativas a respeito da interpretação da Constituição.

- I. O princípio segundo o qual a interpretação da Constituição deve ser realizada a evitar contradição entre suas normas denomina-se princípio do efeito integrador.
- II. O princípio da harmonização é o que dispõe que o intérprete da norma constitucional não

pode chegar a uma posição que subverta, altere ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido pelo legislador constituinte originário.

- III. A concordância prática se traduz no princípio interpretativo pelo qual se exige a coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.
- IV. Entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais: é o que assevera o princípio da força normativa da Constituição.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

26. (TJ/AL/CESPE/UnB-2008) O modo de pensar que foi retomado por Theodor Viehweg, em sua obra *Topik und Jurisprudenz*, tem por principal característica o caráter prático da interpretação constitucional, que busca resolver o problema constitucional a partir do próprio problema, após a identificação ou o estabelecimento de certos pontos de partida. É um método aberto, fragmentário ou indeterminado, que dá preferência à discussão do problema em virtude da abertura textual das normas constitucionais. O método de interpretação constitucional indicado no texto acima é denominado:

- a) tópico-problemático.
- b) hermenêutico-concretizador.
- c) científico-espiritual.
- d) normativo-estruturante.
- e) sistêmico.

27. (TJ/AL/CESPE/UnB-2008) Para Konrad Hesse, as normas jurídicas e a realidade devem ser consideradas em seu condicionamento recíproco. A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade, e a Constituição não configura apenas a expressão de um ser, mas também de um dever ser. Assim, para ser aplicável, a Constituição deve ser conexa à realidade jurídica, social, política; no entanto, ela não é apenas determinada pela realidade social, mas

também determinante desta. É correto afirmar que o texto acima aborda o princípio da:

- a) unidade da Constituição.
- b) força normativa da Constituição.
- c) conformidade funcional.
- d) concordância prática ou da harmonização.
- e) eficácia integradora.

28. (MPE/PE/FCC/2008) No que diz respeito a interpretação constitucional e, especialmente, em conformidade com a doutrina de J. J. Gomes Canotilho, analise:

- I. “O texto de uma Constituição deve ser interpretado de forma a evitar contradições (antinomias) entre suas normas e, sobretudo, entre os princípios constitucionalmente estabelecidos. O intérprete deve considerar a Constituição na sua globalidade procurando harmonizar suas aparentes contradições; não pode interpretar suas disposições como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos integrados em um sistema interno unitário de regras e princípios.”
- II. “O intérprete não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional estabelecido pelo constituinte. Assim, a aplicação das normas constitucionais propostas pelo intérprete não pode implicar alteração na estrutura de repartição de poderes e exercício das competências constitucionais estabelecidas pelo constituinte originário.”

Esses aspectos de interpretação dizem respeito, respectivamente, aos princípios

- a) da harmonização e normativo-estruturante.
- b) normativo-estruturante e hermenêutico-concretizador.
- c) do efeito integrador e da unidade da Constituição.
- d) da unidade da Constituição e da justeza.
- e) da justeza e da força normativa da Constituição.

29. (TJ/PR-2008) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à interpretação das normas constitucionais:

- a) A interpretação conforme a Constituição opera não só como instrumento de controle de constitucionalidade, mas também como princípio de interpretação do texto constitucional.
- b) Na interpretação conforme a Constituição, o intérprete não pode atuar como legislador

positivo.

- c) A interpretação conforme a Constituição em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal produz eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- d) Na interpretação conforme a Constituição, o intérprete pode atuar sobre norma com sentido unívoco.

30. (DP/ES — CESPE/UnB/2009) Assinale certo ou errado:

A interpretação conforme a Constituição determina que, quando o aplicador de determinado texto legal se encontrar frente a normas de caráter polissêmico ou, até mesmo, plurissignificativo, deve priorizar a interpretação que possua um sentido em conformidade com a Constituição. Por conseguinte, uma lei não pode ser declarada inconstitucional, quando puder ser interpretada em consonância com o texto constitucional.

31. (Auditor-Fiscal do Trabalho — ESAF-2010) Praticamente toda a doutrina constitucionalista cita os princípios e as regras de interpretações enumeradas por Canotilho. Entre os princípios e as regras de interpretação abaixo, assinale aquele(a) que não foi elencado por Canotilho:

- a) Unidade da Constituição.
- b) Da máxima efetividade ou da eficiência.
- c) Da supremacia eficaz.
- d) Do efeito integrador.
- e) Da concordância prática ou da harmonização.

32. (AGU — CESPE/UnB/2010) Quanto à hermenêutica constitucional, julgue os itens a seguir:

- a) Pelo princípio da concordância prática ou harmonização, na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre bens jurídicos constitucionalizados, deve-se buscar a coexistência entre eles, evitando-se o sacrifício total de um princípio em relação ao outro.
- b) O método hermenêutico-concretizador caracteriza-se pela praticidade na busca da solução dos problemas, já que parte de um problema concreto para a norma.

33. (TRE-PE — Analista Judiciário — Área Judiciária FCC/2011) No tocante à interpretação das normas constitucionais, o Princípio da Força Normativa da Constituição determina que:

- a) a interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas.
- b) entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais.
- c) os órgãos encarregados da interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta o esquema organizatório funcional constitucionalmente já estabelecido.
- d) na solução dos problemas jurídicos constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social.
- e) a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito seja destinada a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.

34. (Assembleia Legislativa/ES — Procurador — conhecimentos específicos — CESPE/UnB/2011) Assinale certo ou errado (obs.: adaptada pelo autor, na medida em que a prova é de múltipla escolha, com 5 alternativas):

Tem-se a aplicação do denominado princípio da correção funcional quando, por meio da interpretação de algum preceito, busca-se não deturpar o sistema de repartição de funções entre os órgãos e pessoas designados pela CF.

35. (II Defensor Público/AM — Instituto Cidades/2011) Sobre os métodos e princípios hermenêuticos aplicáveis na seara constitucional é correto afirmar que:

- a) Os métodos clássicos de interpretação (literal ou gramatical, histórico, sistêmico e teleológico), segundo a doutrina majoritária, não são aplicáveis na interpretação do texto constitucional.
- b) Segundo o método tópico-problemático, o intérprete parte de uma pré-compreensão da norma para aplicar ao problema, pois considera que o texto constitucional é um limite intransponível para o intérprete.
- c) De acordo com o princípio da correção funcional, o intérprete não pode subverter o esquema organizatório-funcional estabelecido na Constituição, pois, caso contrário, haveria permissão para que um poder invada a competência de outro.
- d) Pelo princípio da eficácia integradora, o intérprete, ao concretizar a Constituição, deve harmonizar os bens jurídicos envolvidos no conflito, de modo que não seja necessário

sacrificar totalmente nenhum deles.

- e) Segundo o princípio da unidade da Constituição, para que não se instaure a total insegurança jurídica, é preciso aceitar o dogma de que existe apenas uma interpretação possível das normas constitucionais.

36. (III Defensor Público/RS — FCC/2011) No que se refere à interpretação e à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, considere as seguintes afirmações:

- I. A interpretação constitucional evolutiva, também denominada de mutação constitucional, não implica alteração no texto constitucional, mas na interpretação da regra.
- II. As normas que consubstanciam os direitos fundamentais são sempre de eficácia e aplicabilidade imediata.
- III. Os direitos e garantias fundamentais consagrados na Carta Magna são ilimitados, tanto que não podem ser utilizados para se eximir alguém da responsabilização pela prática de atos ilícitos.
- IV. No Direito Constitucional brasileiro fala-se de uma certa relatividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, bem como da possibilidade de haver conflito entre dois ou mais deles, oportunidade em que o intérprete deverá se utilizar do princípio da concordância prática ou da harmonização para coordenar e combinar os bens tutelados, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, sempre visando ao verdadeiro significado do texto constitucional.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

37. (Procurador/BACEN — CESPE/UnB/2009) Assinale “certo” ou “errado” (obs.: adaptada pelo autor, na medida em que a prova é de múltipla escolha, com 5 alternativas):

Pela aplicação da teoria dos poderes implícitos, o STF reconhece ao TCU a competência para conceder medidas cautelares no exercício das atribuições que lhe foram fixadas na CF.

38. (Procurador Municipal/Natal — CESPE/UnB/2008) Assinale certo ou errado de acordo com a doutrina dominante referente à interpretação das normas constitucionais (questão adaptada no enunciado e na resposta, sendo a original de múltipla escolha e com 4 alternativas):

A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, defendida por Peter Häberle, propõe que a interpretação constitucional seja tarefa desenvolvida por todos aqueles que vivem a norma, devendo ser inseridos no processo de interpretação constitucional todos os órgãos estatais, os cidadãos e os grupos sociais.

39. (AGU — CESPE/UnB/2012) A respeito (...) da hermenêutica constitucional e do poder constituinte, julgue o item subsequente:

De acordo com o denominado método da tópica, sendo a constituição a representação do sistema cultural e de valores de um povo, sujeito a flutuações, a interpretação constitucional deve ser elástica e flexível.

40. (Procurador Municipal — Prefeitura de Flores da Cunha/RS — FUNDATEC/2012) Pedro Lenza, em sua obra *Direito Constitucional Esquematizado*, Ed. Saraiva (2011), ao tratar da hermenêutica constitucional, identifica uma série de princípios. Em relação a um desses princípios, o autor explica que “deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social”. Assinale a alternativa que identifique a qual dos seguintes princípios este autor está se referindo:

- a) Da eficiência ou da máxima efetividade das normas constitucionais.
- b) Da conformidade social.
- c) Da concordância prática ou da harmonização.
- d) Da interpretação conforme a constituição.
- e) Da proporcionalidade ou da razoabilidade.

■ 3.11.2. Estrutura da Constituição

1. (TJM/2007) O preâmbulo da Constituição de 1988 não menciona explicitamente a seguinte expressão:

- a) os direitos sociais.
- b) os direitos individuais.

- c) o pacto federativo.
- d) o desenvolvimento.
- e) o pluralismo.

2. (TJM/2007) A Constituição Federal apresenta um preâmbulo cuja força obrigatória é:

- a) equivalente a um princípio constitucional.
- b) inexistente.
- c) própria de qualquer regra constitucional.
- d) indicativa, uma vez que consigna a intenção do constituinte, mas deve ser levado em conta no exercício de interpretação.
- e) total, visto que sintetiza o articulado, a exemplo do registro feito pelo constituinte de que a Constituição terá sido promulgada sob a proteção de Deus.

3. (Magistratura MG/2003-2004) No preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988 inexistente referência expressa:

- a) ao Estado Democrático de Direito.
- b) aos direitos sociais.
- c) aos direitos individuais.
- d) ao pacto federativo.
- e) ao desenvolvimento.

4. (MP/PE — 08/2002) O constituinte brasileiro iniciou a redação da Constituição Federal com um preâmbulo, cuja força obrigatória é:

- a) ausente e de nenhuma utilidade, tanto que, no dizer do Preâmbulo, a Constituição é promulgada “sob a proteção de Deus” e o Estado brasileiro é laico.
- b) inerente a ele e a coercibilidade é a regra para todas as normas previstas em uma Constituição.
- c) ausente, destinando-se a indicar a intenção do constituinte, mas deve ser levado em conta quando da interpretação nas normas.
- d) presente, sendo a mesma de toda norma constitucional, com a observação de que se trata de uma norma cogente de eficácia plena.
- e) exacerbada, visto que o Preâmbulo é o resumo das normas constitucionais, garantindo, por si só e sob a proteção de Deus, sua eficácia normativa.

5. (AGU/Procurador Federal/CESPE/UnB/2007) Um partido político ajuizou ação direta de inconstitucionalidade devido à omissão da expressão “sob a proteção de Deus” do preâmbulo da Constituição de determinado Estado da Federação. Para tanto, o partido alegou que o preâmbulo da CF é um ato normativo de supremo princípio básico com conteúdo programático e de absorção compulsória pelos Estados, que o seu preâmbulo integra o texto constitucional e que suas disposições têm verdadeiro valor jurídico. A partir dessa situação hipotética, julgue os próximos itens:

- a) A invocação a Deus, presente no preâmbulo da CF, reflete um sentimento religioso, o que não enfraquece o fato de o Estado brasileiro ser laico, ou seja, um Estado em que há liberdade de consciência e de crença, onde ninguém é privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica.
- b) O preâmbulo constitucional possui destacada relevância jurídica, situando-se no âmbito do direito, e não simplesmente no domínio da política.
- c) O preâmbulo da CF é norma central de reprodução obrigatória na Constituição do referido Estado-membro.

6. (MP/CE — FCC/2011) A invocação à proteção de Deus, constante do Preâmbulo da Constituição da República vigente:

- a) é inconstitucional;
- b) é ilícita;
- c) não tem força normativa;
- d) não foi recepcionada pelo texto constitucional;
- e) é expressão de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais.

7. (OAB — Exame Unificado — CESPE/UnB/2009.2) Com relação ao preâmbulo da CF e às disposições constitucionais transitórias, assinale a opção correta.

- a) Por traçar as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da CF, o preâmbulo constitucional impõe limitações de ordem material ao poder reformador do Congresso Nacional, podendo servir de paradigma para a declaração de inconstitucionalidade.
- b) Considerando-se que o conteúdo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é de direito intertemporal, não é possível afirmar que suas normas ostentam o mesmo grau de eficácia e de autoridade jurídica em relação aos preceitos constantes do texto constitucional.
- c) A doutrina constitucional majoritária e a jurisprudência do STF consideram que o

preâmbulo constitucional não tem força cogente, não valendo, pois, como norma jurídica. Nesse sentido, seus princípios não prevalecem diante de eventual conflito com o texto expresso da CF.

- d) As disposições constitucionais transitórias são normas aplicáveis a situações certas e passageiras; complementares, portanto, à obra do poder constituinte originário e, situando-se fora da CF, não podem ser consideradas parte integrante desta.

8. (TCU — Auditor Federal de Controle Externo — Área Psicologia — CESPE/UnB/2011) O preâmbulo da CF é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais.

9. (III Defensor Público/RS — FCC/2011) Assinale a correta (obs.: adaptada pelo autor, na medida em que a prova é de múltipla escolha, com 5 alternativas):

- a) O preâmbulo da Constituição Federal, ao referir-se expressamente ao pacto federativo, está a indicar a intenção do constituinte em instituir um Estado Democrático e, por isso, deve ser considerado quando da interpretação das normas.
- b) Os direitos sociais estão expressamente referidos no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, assim como os direitos fundamentais e o pluralismo político.

10. De que forma são alteradas as regras contidas no ADCT?

11. (Advogado — IBRAM-DF — CESPE/UnB/2009) O ADCT tem natureza jurídica de norma constitucional, semelhante às normas inseridas no bojo da CF, não havendo desníveis ou desigualdades entre as normas do ADCT e os preceitos constitucionais quanto à intensidade de sua eficácia ou a prevalência de sua autoridade.

12. (Auditor Federal de Controle Externo — TCU — Psicologia — CESPE/UnB/2011) O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que integra o texto constitucional, pode ser objeto de emendas constitucionais.

13. (AGU — Advogado/2004 — CESPE/UnB) Assinale certo ou errado:

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por conter normas que disciplinam situações de transição entre o texto constitucional anterior e o novo texto ou normas que perdem sua vigência após exaurida a sua eficácia provisória, é independente em relação à Constituição.

14. (AGU — Advogado/2012 — CESPE/UnB) A respeito das disposições constitucionais transitórias, da hermenêutica constitucional e do poder constituinte, julgue o item subsequente.

Pelo poder constituinte de reforma, assim como pelo poder constituinte originário, podem ser inseridas normas no ADCT, admitindo-se, em ambas as hipóteses, a incidência do controle de constitucionalidade.

15. (AGU — Advogado/2012 — CESPE/UnB) Julgue o item seguinte, a respeito do ADCT:

Dada a natureza jurídica das normas prescritas no ADCT, por meio delas podem ser estabelecidas exceções às regras constantes no corpo principal da CF.

16. (ABIN — Oficial Técnico de Inteligência — Área de Direito/2010 — CESPE/UnB) No que se refere ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), julgue o próximo item:

A revisão constitucional realizada em 1993, prevista no ADCT, é considerada norma constitucional de eficácia exaurida e de aplicabilidade esgotada, não estando sujeita à incidência do poder reformador.

17. (Advogado — MS Concursos/2010 — CIENTEC/RS) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988:

- a) Consigna mandamentos que não se extinguirão por terem cumprido sua tarefa no tempo e no espaço.
- b) Engloba estipulações quanto as providências a serem adotadas no período de transição.
- c) As disposições transitórias interligam-se com o princípio da recepção.
- d) Os atos transitórios que cumpriram sua função não estão sujeitos à incidência do poder de reforma constitucional certa.
- e) As disposições transitórias participam da técnica jurídica da intemporalidade.

18. (Procurador da República — 27.º Concurso/2013) Assinale a alternativa incorreta:

- a) as normas amparadas por cláusulas pétreas têm importantes repercussões hermenêuticas, mas não superioridade jurídica sobre as demais normas constitucionais editadas pelo poder constituinte originário;

- b) o preâmbulo da Constituição não tem força normativa autônoma, podendo, no entanto, ser utilizado como reforço argumentativo ou diretriz hermenêutica;
- c) é impossível a reforma constitucional das normas transitórias do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porque incompatível com a provisoriedade que lhes é ínsita;
- d) é entendimento consolidado do STF de que o Estado-membro não pode criar procedimento mais rigoroso do que o previsto na Constituição Federal para a emenda de suas Constituições.

19. (Procurador da República — 27.º Concurso/2013) Assinale a alternativa incorreta (adaptada — a prova do concurso tem 4 alternativas):

- a) o direito à liberdade de crença depende não apenas do direito de exprimir a crença, mas de uma autodeterminação existencial a partir dela;
- b) a laicidade do Estado, tal como concebida pela Constituição de 1988, significa a adoção de uma perspectiva refratária à expressão pública da religiosidade por indivíduos e grupos.

20. (Defensor Público MS — VUNESP/2014) No que se refere à interpretação da natureza jurídica do preâmbulo da Constituição, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- a) o preâmbulo da Constituição é normativo, apresentando a mesma natureza do articulado da Constituição e, conseqüentemente, serve como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade.
- b) o preâmbulo da Constituição não constitui norma central, não tendo força normativa e, conseqüentemente, não servindo como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade.
- c) o preâmbulo da Constituição possui natureza histórica e política, entretanto, se situa no âmbito dogmático e, conseqüentemente, serve como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade.
- d) o preâmbulo da Constituição possui natureza interpretativa ou unificadora e traz sentido às categorias jurídicas da Constituição e, portanto, trata-se de norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais.

21. (Analista legislativo — Consultor Legislativo CD — CESPE/UnB/2014) À luz dos princípios fundamentais de direito constitucional positivo brasileiro, julgue o item

a seguir.

Quando um estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua constituição, contraria a CF, pois tal invocação é norma central do direito constitucional positivo brasileiro.

■ GABARITO ■

■ 3.11.1. Hermenêutica
1. “errado”.
2. “a”.
3. “d”.
4. “verdadeiro”.
5. “d”.
6. “c”.
7. “certo”.
8. “c”.
9. “d”.
10. “e”. <i>Vide</i> parte teórica.
11. “b”. <i>Vide</i> parte teórica.
12. “d”. <i>Vide</i> parte teórica.
13. “certo”.
14. “b”.

15. “errado”.
16. “errado”.
17. “errado”. A definição acima exposta, segundo Canotilho, é do princípio do efeito integrador.
18. “certo”.
19. “certo”.
20. “certo”.
21. “certo”.
22. “errado”.
23. “certo”.
24. “c”.
25. “d”.
26. “a”.
27. “b”.
28. “d”.
29. “d”.
30. “certo”.
31. “c”.
32. a) “certo”. b) “errado” . O item em análise descreve o método tópico-problemático.
33. “b”.
34. “certo”.

35. “c”.
36. “b”.
37. “certo”. Conforme parte teórica e MS 26.547.
38. “certo”.
39. “errado”. A definição descreve o método científico-espiritual.
40. “a”.

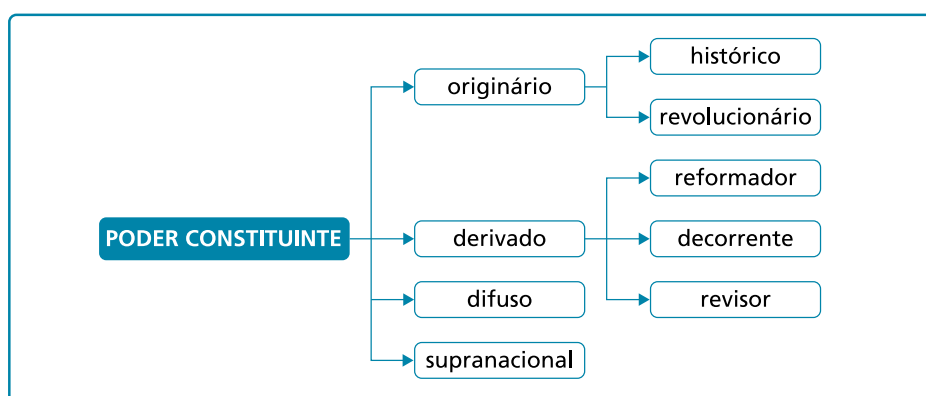
■ 3.11.2. Estrutura da Constituição
1. “c”.
2. “d”.
3. “d”. Pedimos vênia para transcrever o Preâmbulo da CF/88, destacando as referências expressas descritas nas alíneas da presente questão. Com todo o respeito, este modelo de pergunta não mede conteúdo, mas exige apenas o conhecimento da literalidade do texto. Infelizmente, contudo, esse detalhe pode fazer a diferença. Então vamos lá: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil”.
4. “c”. <i>Vide</i> parte teórica.
5. Item “a” — correto; item “b” — errado; e item “c” — errado. <i>Vide</i> parte teórica.
6. “c”.

7. “c”.
8. “errado”.
9. “b”.
10. Como podemos perceber, as regras contidas no ADCT têm natureza constitucional, pois pertencem à Constituição. Fazendo alusão a um livro, seria a parte final dele, o epílogo. Assim, as normas do ADCT, como as regras do corpo da Constituição, são alteradas por meio de emendas constitucionais, como ocorreu, v.g., nas ECs ns. 2/92, 6/94 (Revisão); 2/92, 10, 12 e 14/96, 17/97, 21/99, 27/2000, 29/2000, 30/2000, 31/2000, 37/2002, 38/2002, 40/2003, 42/2003, 43/2004, 53/2006, 54/2007, 56/2007, 57/2008, 59/2009, 60/2009, 62/2009, 67/2010, 68/2011, 73/2014, 78/2014, 79/2014, 80/2014, 83/2014, 88/2015 etc.
11. “certo”.
12. “certo”.
13. “errado”.
14. “errado”. Em um primeiro momento, o CESPE/UnB lançou em gabarito preliminar a resposta como sendo “certo”. Contudo, após os recursos, o gabarito foi alterado, nos seguintes termos: “é admitido o controle de constitucionalidade em relação às normas inseridas no ADCT pelo poder constituinte de reforma, nas hipóteses em que as emendas à Constituição o podem ser. A doutrina ressalta a possibilidade de o poder de reforma também inserir norma no ADCT, as quais são também passíveis de controle de constitucionalidade. Nesse sentido: ‘da mesma forma, tanto o constituinte originário como o de reforma podem deliberar sobre temas concretos, em regulação por prazo definido, preferindo fazê-lo fora do Texto principal, mas com o mesmo valor jurídico das normas ali contidas’ (<i>Curso de Direito Constitucional</i>. Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. 6. ed., pág. 90). ‘Evidentemente também que as normas acrescentadas ao ADCT pelo poder constituinte de reforma são suscetíveis de controle de constitucionalidade, nas hipóteses em que as emendas à Constituição o podem ser’ (obra citada, mesma página). Dessa forma, fica clara a necessidade de se alterar o gabarito já que em todo o tempo se justificou o cabimento do controle em face da norma inserida pelo poder de reforma e não pelo poder constituinte originário, já que as ‘normas constitucionais fruto do trabalho do poder constituinte originário serão sempre constitucionais, não se podendo falar em controle de sua constitucionalidade.’ (<i>Direito Constitucional Esquematizado</i>. Pedro Lenza. 15. ed., pág. 271). A hipótese é de alteração do

gabarito para se considerar a assertiva errada” (justificativa de alteração do gabarito feita pelo próprio CESPE/UnB).
15. “certo”.
16. “certo”. Por ter produzido os seus efeitos, já que realizado o referido plebiscito, o art. 3.º do ADCT tornou-se norma constitucional de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, não se admitindo, nesse sentido, uma nova revisão nos moldes da timidamente realizada em 1993.
17. “a”.
18. “c”.
19. “b”. Conforme estudamos na parte teórica (<i>item 3.10.1.3</i>), diferentemente do enunciado, laicidade significa neutralidade religiosa. Laicismo é que significa intolerância.
20. “b”.
21. “errado”.

PODER CONSTITUINTE

■ 4.1. ESQUEMA GERAL



■ 4.2. CONCEITO E TITULARIDADE

De acordo com a lição de Canotilho, “o poder constituinte se revela sempre como uma questão de ‘poder’, de ‘força’ ou de ‘autoridade’ política que está em condições de, numa determinada situação concreta, **criar**, **garantir** ou **eliminar** uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política”.¹

A **titularidade** do poder constituinte, como aponta a doutrina moderna, pertence ao *povo*.² Apesar disso, lembramos que seu grande teórico, o abade de Chartres, Emmanuel Joseph Sieyès, por meio do panfleto denominado “Que é o terceiro Estado?” (*Qu’est-ce que le tiers État?*), apontava como titular a *nação*. (*Obs.*: para as provas, adotar o posicionamento de que a titularidade do poder constituinte pertence ao povo, sabendo do conceito clássico exposto por Sieyès.)

Nesse sentido, seguindo a tendência moderna, o parágrafo único do art. 1.º da CF/88 estabelece que todo poder emana do povo. E quem compõe o povo? Os integrantes do povo, para Temer, são aqueles catalogados no art. 12 da CF/88.³

Distingue-se, por fim, o que já referimos, *titularidade de exercício* do poder. O exercício do poder constituinte, em particular, está reservado a ente diverso do povo, como determinaremos ao tratar das *formas de expressão do poder constituinte originário*.

■ 4.3. HIATO CONSTITUCIONAL (REVOLUÇÃO — MUTAÇÃO — REFORMA — HIATO AUTORITÁRIO)

A expressão “**hiato constitucional**” se deve a Ivo Dantas, quando desenvolveu o tema em sua dissertação de mestrado defendida em 1976.⁴

Dantas analisa a relação entre o “direito legislado”, a “Constituição política” e a “sociedade” ou “realidade social”.

O **hiato constitucional**, também chamado pelo autor de **revolução**, verifica-se quando há um **choque** (ou “divórcio”) entre o conteúdo da *Constituição política* (uma das formas do *direito legislado*) e a *realidade social ou sociedade*.

De acordo com o que define, a **dinâmica constitucional** (Garcia Pelayo) pode ser caracterizada como “... a constante tentativa de adaptar o texto político às *novas realidades-valores sociais*, o que, quando inexistente, dará margem a **Hiato Constitucional** ou, se desejarem, **Revolução**...”.

Assim, a “revolução” deve ser encarada “... como uma quebra do processo político e histórico normal da organização política”.

Tomando por base essa ideia, qual seja, que o *hiato constitucional* caracteriza verdadeira **lacuna**, **intervalo**, **interrupção de continuidade**, entendemos que vários fenômenos poderão ser verificados, destacando-se:

- convocação da **Assembleia Nacional Constituinte** e elaboração de nova Constituição;

■ **mutação constitucional;**

■ **reforma constitucional;**

■ **hiato autoritário.**

A partir da quebra do processo constitucional, vale dizer, diante da não correspondência entre o texto posto e a realidade social, poderá surgir espaço para o denominado “momento constituinte” democrático e, assim, diante da manifestação do *poder constituinte originário*, a elaboração de novo documento que encontre legitimidade social.

Ainda, diante da *lacuna* poderá também ser verificada a necessidade de mudança no sentido interpretativo da norma posta, ou seja, o instituto, já desenvolvido no *item 3.1*, da **mutação constitucional**, pelo qual a “letra fria” do texto é mantida, mas se atribui um novo sentido interpretativo, nos exatos termos da realidade social evolutiva.

Em outro sentido, o vácuo de correspondência poderá sinalizar a necessidade de manifestação (formal) do **poder de reforma**, por meio das emendas constitucionais, fazendo com que haja a manifestação do *poder constituinte derivado reformador*.

Finalmente, a *quebra* poderá dar espaço para a ilegítima outorga constitucional, manifestando-se o poder autoritário e fazendo com que o *hiato constitucional* se transforme em **hiato autoritário**, que persistirá mesmo diante da edição de textos (ilegítimos) como foi, por exemplo, durante o regime militar, o AI-5, textos que buscam suprir o hiato constitucional, mas, por falta de legitimidade, sucumbem, abrindo espaço para o nefasto e combatido *hiato autoritário*.

■ 4.4. PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO (GENUÍNO OU DE 1.º GRAU)

■ 4.4.1. Conceito

O **poder constituinte originário** (também denominado **inicial**, **inaugural**,

genuíno ou de **1.º grau**) é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente.

O objetivo fundamental do poder constituinte originário, portanto, é **criar um novo Estado**, diverso do que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte precedente.

Reproduzimos interessante conceituação trazida por Temer a respeito do assunto: “ressalte-se a ideia de que surge novo Estado a cada nova Constituição, provenha ela de movimento revolucionário ou de assembleia popular. O Estado brasileiro de 1988 não é o de 1969, nem o de 1946, o de 1937, de 1934, de 1891, ou de 1824. Historicamente é o mesmo. Geograficamente pode ser o mesmo. Não o é, porém, juridicamente. A cada manifestação constituinte, editora de atos constitucionais como Constituição, Atos Institucionais e até Decretos (veja-se o Dec. n. 1, de 15.11.1889, que proclamou a República e instituiu a Federação como forma de Estado), nasce o Estado. Não importa a rotulação conferida ao ato constituinte. Importa a sua natureza. Se dele decorre a certeza de rompimento com a ordem jurídica anterior, de edição normativa em desconformidade intencional com o texto em vigor, de modo a invalidar a normatividade vigente, tem-se novo Estado”.⁵

■ 4.4.2. Uma subdivisão

O poder constituinte originário pode ser subdividido em **histórico** (ou **fundacional**) e **revolucionário**. *Histórico* seria o verdadeiro poder constituinte originário, estruturando, pela primeira vez, o Estado. *Revolucionário* seriam todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando uma nova, um novo Estado.

■ 4.4.3. Características

O poder constituinte originário é *inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano na tomada de suas decisões, um poder de fato e*

político, permanente.

a) inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo, por completo, com a ordem jurídica anterior;

b) autônomo, visto que a estruturação da nova constituição será determinada, autonomamente, por quem exerce o poder constituinte originário;

c) ilimitado juridicamente, no sentido de que não tem de respeitar os limites postos pelo direito anterior, com as ressalvas a seguir indicadas e que passam a ser uma tendência para os concursos públicos;

d) incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, porque não tem de submeter-se a qualquer forma prefixada de manifestação;

e) poder de fato e poder político, podendo, assim, ser caracterizado como uma energia ou força social, tendo natureza pré-jurídica, sendo que, por essas características, a nova ordem jurídica começa com a sua manifestação, e não antes dela;

f) permanente, já que o poder constituinte originário não se esgota com a edição da nova Constituição, **sobrevivendo** a ela e fora dela como forma e expressão da **liberdade humana**, em verdadeira ideia de **subsistência**. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, essa característica decorre de fórmula clássica prevista no art. 28 da *Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão*, editada como *preâmbulo da Constituição francesa de 1793* e “... no sentido de que o homem, embora tenha tomado uma decisão, pode rever, pode mudar posteriormente essa decisão...”.⁶ Isso não significa que o poder constituinte originário permanente e “adormecido” sairá desse estado de “hibernação” e de “latência” a todo e qualquer momento, até porque instauraria indesejada insegurança jurídica. Para tanto, deve haver o “momento constituinte”, uma situação tal que justifique e requeira a **quebra abrupta** da ordem jurídica.

Lembramos, contudo, a corrente *jusnaturalista*, para a qual o poder

constituente originário não seria totalmente autônomo na medida em que haveria uma limitação imposta: ao menos o respeito às normas de direito natural. Como o Brasil adotou a corrente **positivista**, o poder constituinte originário é totalmente ilimitado (do ponto de vista jurídico, reforce-se), apresentando natureza **pré-jurídica**, uma energia ou força social, já que a ordem jurídica começa com ele e não antes dele. Assim, para o Brasil e os positivistas, nem mesmo o *direito natural* (por alguns denominado *direito suprapositivo*)⁷ limitaria a atuação do poder constituinte originário.

Anota J. H. Meirelles Teixeira: “... esta *ausência de vinculação*, note-se bem, é apenas de caráter *jurídico-positivo*, significando apenas que o Poder Constituinte não está ligado, em seu exercício, por *normas jurídicas anteriores*. Não significa, porém, e nem poderia significar, que o Poder Constituinte seja um poder arbitrário, absoluto, que não conheça quaisquer limitações. *Ao contrário, tanto quanto a soberania nacional, da qual é apenas expressão máxima e primeira, está o Poder Constituinte limitado pelos grandes princípios do Bem Comum, do Direito Natural, da Moral, da Razão*. Todos estes grandes princípios, estas exigências ideais, que não são jurídico-positivas, devem ser respeitados pelo Poder Constituinte, para que este se exerça legitimamente. O Poder Constituinte deve acatar, aqui, ‘a voz do reino dos ideais promulgados pela consciência jurídica’, na bela expressão de Recaséns Siches”.⁸

Nesse sentido, **afastando-se** da ideia de *onipotência do poder constituinte* derivada da *teologia política* “... que envolveu a sua caracterização na Europa da Revolução Francesa (1789)”, atualmente ultrapassada, posiciona-se Canotilho, o qual, sugerindo ser entendimento da doutrina moderna, observa que o *poder constituinte* “... é estruturado e obedece a **padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais** radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, nesta medida, considerados como ‘vontade do povo’”. Fala, ainda, na necessidade de observância de **princípios de justiça** (suprapositivos e supralegais) e, também, dos **princípios de direito internacional** (princípio da independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância de direitos humanos — neste último caso de vinculação

jurídica, chegando a doutrina a propor uma juridicização e evolução do poder constituinte).⁹

Paulo Branco também perfilha o entendimento da existência de **limitações políticas** inerentes ao exercício do poder constituinte originário.

Em suas palavras, “se o poder constituinte é a **expressão da vontade política da nação**, não pode ser entendido sem a referência aos **valores éticos, religiosos, culturais** que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Por isso, um grupo que se arroge a condição de representante do poder constituinte originário, se se dispuser a redigir uma Constituição que hostilize esses valores dominantes, não haverá de obter o acolhimento de suas regras pela população, não terá êxito no seu empreendimento revolucionário e **não será reconhecido como poder constituinte originário**. Afinal, só é dado falar em atuação do poder constituinte originário se o grupo que diz representá-lo colher a anuência do povo, ou seja, se vir ratificada a sua invocada representação popular. Do contrário, estará havendo apenas uma insurreição, a ser sancionada como delito penal. Quem tenta romper a ordem constitucional para instaurar outra e não obtém a adesão dos cidadãos não exerce poder constituinte originário, mas age como rebelde criminoso”.¹⁰

■ 4.4.4. Poder constituinte originário formal e material

A doutrina ainda fala em poder constituinte *formal* e *material*:

■ **formal:** é o ato de criação propriamente dito e que atribui a “roupagem” com *status* constitucional a um “complexo normativo”;

■ **material:** é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito constitucional formal com o *status* de norma constitucional. Assim, será o orientador da atividade do constituinte originário formal que, por sua vez, será o responsável pela “roupagem” constitucional. O material diz o que é constitucional; o formal materializa e sedimenta como constituição. O material precede o formal, estando ambos interligados.

Assim, para Jorge Miranda, o **poder constituinte formal** confere “... *estabilidade e garantia* de permanência e de supremacia hierárquica ou sistemática ao princípio normativo inerente à **Constituição material**. Confere *estabilidade*, visto que a certeza do Direito exige o estatuto da regra. Confere *garantia*, visto que só a Constituição formal coloca o poder constituinte material (ou o resultado da sua ação) ao abrigo das vicissitudes da legislação e da prática quotidiana do Estado e das forças políticas”.¹¹

■ 4.4.5. Formas de expressão

Duas são as formas de expressão do poder constituinte originário: **a) outorga;** **b) assembleia nacional constituinte** (ou **convenção**).

■ **outorga:** caracteriza-se pela declaração unilateral do agente revolucionário (movimento revolucionário — exemplo: Constituições de 1824, 1937, 1967 e EC n. 1/69, lembrando que a Constituição de 1946 já havia sido suplantada pelo Golpe Militar de 1964 — *AI 1, de 09.04.1964*). Conforme vimos, embora a Constituição de 1946 continuasse existindo formalmente, o País passou a ser governado pelos Atos Institucionais e Complementares, com o objetivo de consolidar a “Revolução Vitoriosa”, que buscava combater e “drenar o bolsão comunista” que assolava o Brasil;

■ **assembleia nacional constituinte** ou **convenção:** por seu turno, nasce da deliberação da representação popular, destacando-se os seguintes exemplos: CF de 1891, 1934, 1946 e 1988.

■ 4.4.6. A proposta de convocação de uma “assembleia nacional constituinte exclusiva e específica” para a reforma política: aberração jurídica; violência ao sistema

Inegavelmente, o Estado brasileiro precisa passar pela “engavetada” e necessária **reforma política** e, como se sabe, dentro do modelo atual, o instrumento para a sua implementação seria uma proposta de emenda à

Constituição (PEC).

Buscando dar uma resposta aos vários movimentos sociais que tomaram conta do país no ano de 2013 (manifestações, passeatas, reivindicações etc.), deflagrados pelo aumento das tarifas de ônibus (e, claro, todos sabem que não foram os “vinte centavos” o fator de mobilização e do descontentamento com o modelo de representação), a Presidente Dilma Rousseff, em discurso um pouco tardio, enaltecendo a “voz das ruas”, propôs a **convocação de uma assembleia nacional constituinte exclusiva e específica para a reforma política**.

Em suas palavras, ditas na abertura da reunião com governadores e prefeitos realizada em **24.06.2013**, propondo soluções para a crise, sugeriu 5 *pactos nacionais* (responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transportes públicos e educação pública). No tocante à **reforma política**, sugeriu a sua implementação por meio de uma **constituente exclusiva**, autorizada por **plebiscito popular**.¹²

Nesse ponto, com o máximo respeito, mesmo que buscando “escutar a voz das ruas”, mesmo que houvesse legitimação por plebiscito popular, admitir uma **constituente específica** ensejaria total **afronta** à Constituição.

Conforme dissemos e retomamos a seguir, a única maneira de se alterar a Constituição no momento atual é mediante a aprovação de uma PEC, com todos os limites explícitos e estabelecidos no art. 60 da CF/88, bem como os limites implícitos que decorrem do sistema.

A proposta de se estabelecer uma constituinte exclusiva e específica seria o mesmo que admitir uma parcial manifestação do poder constituinte originário, o que, por suas características e forma de expressão, seria inimaginável.

O **poder constituinte originário** (também denominado **inicial**, **inaugural**, **genuíno** ou de **1.º grau**), ao se manifestar, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente, cria o novo Estado desvinculado do que então vigorava, saindo do seu estado de “hibernação” e “latência”, em razão da existência de inquestionável “momento constituinte”.

Não é o caso. Não se vislumbra esse tal “momento constituinte”. A convocação de instrumento de alteração específico afrontaria, dentre outros, a

implícita proibição de se alterar a titularidade do poder constituinte originário, bem como a do **poder de reforma que se implementa por ato exclusivo do Congresso Nacional**, assim como os seus limites colocados na Constituição.

É preciso, sim, escutar a voz do povo, mas não se pode violentar o processo de reforma da Constituição.

Como alternativa, e o tema precisa ser amadurecido, poderíamos pensar nos instrumentos de soberania popular (e esse passou a ser o novo discurso da Presidente Dilma), destacando-se o plebiscito e o referendo, não para se dar um “cheque em branco” para a tal constituinte parcial e específica, mas para **referendar** — e esse seria um modelo melhor — uma eventual alteração que fosse concretizada e, claro, respeitando o modelo constitucional, qual seja, por necessária e formal proposta de emenda, nos limites das regras estabelecidas pelo poder constituinte originário.

■ 4.5. PODER CONSTITUINTE DERIVADO (INSTITUÍDO, CONSTITUÍDO, SECUNDÁRIO, DE 2.º GRAU OU REMANESCENTE)

■ 4.5.1. Conceito e espécies [13](#)

PODER CONSTITUINTE	
■ Poder constituinte derivado ■ Natureza jurídica	■ Poder constituinte originário ■ Poder de fato¹³ ■ Poder político ■ Energia ou força social ■ Natureza pré-jurídica ■ A ordem jurídica começa com o poder constituinte originário e não antes dele

O **poder constituinte derivado** é também denominado **instituído, constituído, secundário, de segundo grau, remanescente**.

Como o próprio nome sugere, o poder constituinte *derivado* é criado e

instituído pelo *originário*.

Ao contrário de seu “criador”, que é, do ponto de vista jurídico, ilimitado, incondicionado, inicial, o *derivado* deve obedecer às regras colocadas e impostas pelo *originário*, sendo, nesse sentido, limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos.

Alguns autores preferem a utilização da terminologia *competências*, em vez de poder constituinte derivado, pois só seria poder constituinte o que derivasse diretamente da soberania popular e fosse ilimitado. No entanto, mantemos a utilização da expressão “poder constituinte” na medida em que dele decorre a produção de normas de caráter constitucional. (nas provas preambulares também vem sendo, de maneira geral, utilizada a nomenclatura “poder constituinte derivado”.)

Derivam, pois, do originário o **reformador**, o **decorrente** e o **revisor**. Vejamos cada um deles.

■ 4.5.2. Poder constituinte derivado reformador

O **poder constituinte derivado reformador**, chamado por alguns de *competência reformadora*,¹⁴ tem a capacidade de modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, estabelecido pelo originário, sem que haja uma verdadeira *revolução*.

O poder de reforma constitucional, assim, tem **natureza jurídica**, ao contrário do originário, que é um *poder de fato*, um poder *político*, ou, segundo alguns, *uma força ou energia social*.¹⁵

A manifestação do poder constituinte reformador verifica-se através das **emendas constitucionais** (arts. 59, I, e 60 da CF/88), que abordaremos melhor quando tratarmos das espécies normativas.

Neste momento, já adiantamos algumas características do poder de reforma, decorrentes de sua natureza constituída, instituída, ou de segundo grau. Como vimos, ao contrário do originário, que é incondicionado, o **derivado** é **condicionado** pelas regras colocadas pelo originário, este último, sim, um poder

de fato que tudo pode!

Enfim, o originário permitiu a alteração de sua obra, mas obedecidos alguns limites como: *quorum* qualificado de 3/5, em cada Casa, em dois turnos de votação para aprovação das emendas (art. 60, § 2.º); proibição de alteração da Constituição na vigência de estado de sítio, defesa, ou intervenção federal (art. 60, § 1.º), um núcleo de matérias intangíveis, vale dizer, as *cláusulas pétreas* do art. 60, § 4.º, da CF/88 etc.

Dessa forma, além das **limitações expressas** ou **explícitas** (*formais ou procedimentais* — art. 60, I, II, III e §§ 2.º, 3.º e 5.º; *circunstanciais* — art. 60, § 1.º; e *materiais* — art. 60, § 4.º), a doutrina identifica, também, as **limitações implícitas** (como *impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte derivado reformador*, bem como a *proibição de se violar as limitações expressas*, não tendo sido adotada, no Brasil, portanto, a *teoria da dupla revisão*, ou seja, uma primeira revisão acabando com a limitação expressa e a segunda reformando aquilo que era proibido).¹⁶

■ 4.5.3. Poder constituinte derivado decorrente

■ 4.5.3.1. Estados-Membros

O **poder constituinte derivado decorrente**,¹⁷ assim como o reformador, por ser derivado do originário e por ele criado, é também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário.

Sua missão é **estruturar** a Constituição dos Estados-Membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, **modificá-la**. Tal competência decorre da capacidade de **auto-organização** estabelecida pelo poder constituinte originário. Como veremos ao tratar dos Estados-Membros, no tópico Federação (*item 7.5*), a eles foi atribuída *autonomia*, manifestada pela capacidade de **auto-organização** (art. 25, *caput*); **autogoverno** (arts. 27, 28 e 125, que estabelecem regras para a estruturação

dos “*Poderes*” Legislativo: *Assembleia Legislativa*; Executivo: *governador do Estado*; e Judiciário: *Tribunais e juízes*) e **autoadministração** (arts. 18 e 25 a 28 — regras de competência legislativas e não legislativas, que serão oportunamente estudadas).

Segundo Anna Cândida da Cunha Ferraz, em uma das mais completas monografias sobre o tema no direito pátrio, o poder constituinte derivado decorrente se divide em **duas modalidades**:

■ **poder constituinte decorrente inicial (“instituidor” ou “institucionalizador”)**: responsável pela **elaboração** da Constituição estadual. Como anotou Anna Cândida, “... intervém para exercer uma tarefa de caráter nitidamente constituinte, qual seja a de estabelecer a organização fundamental de entidades componentes do Estado Federal. Tem o Poder Constituinte Decorrente um caráter de complementaridade em relação à Constituição; destina-se a perfazer a obra do Poder Constituinte Originário nos Estados Federais, para estabelecer a Constituição dos seus Estados componentes”.¹⁸

■ **poder constituinte decorrente de revisão estadual (“poder decorrente de segundo grau”)**: tem a finalidade de **modificar** o texto da Constituição estadual, implementando as reformas necessárias e justificadas e nos limites colocados na própria constituição *estadual* (nesse sentido, por derivar de um poder que já derivou de outro, caracteriza-se como de *segundo grau*)¹⁹ e na *federal*.

Pois bem, em relação à *capacidade de auto-organização*, prevista no art. 25, *caput*, da CF/88, foi categórico o poder constituinte originário ao definir que “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, **observados os princípios desta Constituição**”. Esta última parte do texto demonstra, claramente, o caráter de derivação e vinculação do poder decorrente em relação ao originário; vale dizer, os Estados têm a capacidade de auto-organizar-se, desde que, é claro, observem as regras que foram estabelecidas pelo poder constituinte originário. Havendo afronta, estaremos diante de um vício formal ou material, caracterizador da inconstitucionalidade.

E o que deve ser entendido por **princípios desta Constituição**? Quais são os

limites à manifestação do **poder constituinte derivado decorrente**? Em interessante síntese, da qual nos valem, Uadi Lammêgo Bulos fixa, como limites à manifestação do poder constituinte derivado decorrente, os **princípios constitucionais sensíveis**, os **princípios constitucionais estabelecidos** (organizatórios) e os **princípios constitucionais extensíveis**:[20](#)

■ **princípios constitucionais sensíveis**: terminologia adotada por Pontes de Miranda; encontram-se expressos na Constituição, daí serem também denominados *princípios apontados ou enumerados*. Nesse sentido, os Estados-Membros, ao elaborar as suas constituições e leis, deverão observar os limites fixados no **art. 34, VII, “a-e”, da CF/88**, sob pena de, declarada a inconstitucionalidade da referida norma e a sua suspensão insuficiente para o restabelecimento da normalidade, ser decretada a intervenção federal no Estado (a este assunto voltaremos no *item 6.7.5*, quando estudarmos a *ADI interventiva*, no capítulo sobre o controle de constitucionalidade);

■ **princípios constitucionais estabelecidos (organizatórios)**: segundo Bulos, “... são aqueles que limitam, vedam, ou proíbem a ação indiscriminada do Poder Constituinte Decorrente. Por isso mesmo, funcionam como balizas reguladoras da capacidade de auto-organização dos Estados (...) podem ser extraídos da interpretação do conjunto de normas centrais, dispersas no Texto Supremo de 1988, que tratam, por exemplo, da repartição de competência, do sistema tributário nacional, da organização dos Poderes, dos direitos políticos, da nacionalidade, dos direitos e garantias individuais, dos direitos sociais, da ordem econômica, da educação, da saúde, do desporto, da família, da cultura etc.”. O autor os divide em três tipos: *a) limites explícitos vedatórios*: proíbem os Estados de praticar atos ou procedimentos contrários ao fixado pelo poder constituinte originário — exs.: arts. 19, 35, 150, 152, ou **limites explícitos mandatórios**: restrições à liberdade de organização — exs.: arts. 18, § 4.º, 29, 31, § 1.º, 37 a 42, 92 a 96, 98, 99, 125, § 2.º, 127 a 130, 132, 134, 135, 144, IV e V, §§ 4.º a 7.º; *b) limites inerentes*: implícitos ou tácitos, vedam qualquer possibilidade de invasão de competência por parte dos Estados-Membros; *c) limites decorrentes*: decorrem de disposições expressas. Exs.: necessidade de observância do princípio federativo, do

Estado Democrático de Direito, do princípio republicano (art. 1.º, *caput*); da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III); da igualdade (art. 5.º, *caput*); da legalidade (art. 5.º, II); da moralidade (art. 37), do combate a desigualdades regionais (art. 43) etc.;

■ **princípios constitucionais extensíveis:** mais uma vez na conceituação de Bulos, “são aqueles que integram a estrutura da federação brasileira, relacionando-se, por exemplo, com a forma de investidura em cargos eletivos (art. 77), o processo legislativo (arts. 59 e s.)²¹, os orçamentos (arts. 165 e s.), os preceitos ligados à Administração Pública (arts. 37 e s.) etc.”.

Finalmente, é de lembrar que o exercício do poder constituinte derivado decorrente foi concedido às **Assembleias Legislativas**, nos termos do art. 11, *caput*, do ADCT, que diz: “Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, **obedecidos os princípios desta**” (destacamos).

■ 4.5.3.2. Distrito Federal

O **Distrito Federal**, de acordo com o art. 32, *caput*, da CF/88, será regido por **lei orgânica**, votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da **Câmara Legislativa**, que a promulgará. Tal lei orgânica deverá obedecer aos princípios estabelecidos na **Constituição Federal**.²²

Dessa forma, embora a posição particular ocupada pelo DF na Federação, já que a sua **autonomia** é **parcialmente tutelada pela União** (arts. 21, XIII e XIV, e 22, XVII), além de **acumular** competências legislativas reservadas tanto aos **Estados** como aos **Municípios** (art. 32, § 1.º), a vinculação da lei orgânica será **diretamente** com a CF.

Nesse sentido, em interessante demonstração, o Min. Carlos Britto afirmou que, “conquanto submetido a regime constitucional **diferenciado**, o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos **Estados-membros** do que da arquitetura constitucional dos Municípios” (ADI 3.756, j. 21.06.2007, *DJ* de

19.10.2007).

Assim, na medida em que a derivação é **direta** em relação à Constituição Federal, parece razoável afirmarmos, **mudando de posição firmada em edições anteriores à 13.^a,²³** que, no âmbito do DF, verifica-se a **manifestação do poder constituinte derivado decorrente**, qual seja, a competência que o DF tem para elaborar a sua lei orgânica (verdadeira **Constituição distrital**) ou modificá-la, sujeitando-se aos mesmos limites já apontados para os Estados-Membros e, pois, aplicando-se, por analogia, o art. 11 do ADCT.²⁴

Por esse motivo, é perfeitamente possível o controle concentrado no âmbito do **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)** tendo como paradigma a Lei Orgânica do DF, com a mesma natureza das Constituições Estaduais, regra essa, inclusive, introduzida, de modo expresso, no art. 30 da Lei n. 9.868/99 e, também, na Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STF:

“EMENTA: Antes de adentrar no mérito da questão aqui debatida, anoto que, muito embora não tenha o constituinte incluído o Distrito Federal no art. 125, § 2.º, que atribui competência aos Tribunais de Justiça dos Estados para instituir a representação de inconstitucionalidade em face das constituições estaduais, a **Lei Orgânica do Distrito Federal** apresenta, no dizer da doutrina, a **natureza de verdadeira Constituição local**, ante a autonomia política, administrativa e financeira que a Carta confere a tal ente federado. Por essa razão, entendo que se mostrava **cabível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade** pelo MPDFT no caso em exame” (RE 577.025, voto do Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.12.2008, Plenário, *DJE* de 06.03.2009).

■ 4.5.3.3. *Municípios: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?*

Não.

Os **Municípios** (que por força dos arts. 1.º e 18 da CF/88 fazem parte da

Federação brasileira, sendo, portanto, autônomos em relação aos outros componentes, na medida em que também têm autonomia “F.A.P.” — financeira, administrativa e política) elaborarão **leis orgânicas** como se fossem “Constituições Municipais”.

Desse modo, a *capacidade de auto-organização municipal* está delimitada no art. 29, *caput*, da CF/88, e seu exercício caberá à Câmara Municipal, nos termos do parágrafo único do art. 11 do ADCT: “promulgada a Constituição do Estado, caberá à **Câmara Municipal**, no prazo de 6 meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, **respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual**” (destacamos).

Como se observa, o respeito ao conteúdo dar-se-á tanto em relação à **Constituição Estadual** como à **Federal**, obedecendo, desta feita, como advertiram Araujo e Nunes, “a dois graus de imposição legislativa constitucional”. Em virtude disso e trazendo à baila entendimento jurisprudencial emanado pelo TJSP, os autores concluem que “o poder constituinte decorrente, conferido aos Estados-membros da Federação, **não foi estendido aos Municípios**” (destacamos). [25](#)

Nesse sentido, Noemia Porto assinala: “o **poder constituinte derivado decorrente** deve ser de **segundo grau**, tal como acontece com o poder revisor e o poder reformador, isto é, encontrar sua **fonte de legitimidade direta da Constituição Federal**. No caso dos **Municípios**, porém, se descortina um poder de **terceiro grau**, porque mantém relação de subordinação com o poder constituinte estadual e o federal, ou, em outras palavras, observa necessariamente dois graus de imposição legislativa constitucional. Não basta, portanto, ser componente da federação, sendo necessário que o poder de auto-organização decorra diretamente do poder constituinte originário. Assim, o **poder constituinte decorrente**, conferido aos Estados-membros e ao Distrito Federal, **não se faz na órbita dos Municípios**. Por essa razão, ato local questionado em face da lei orgânica municipal enseja controle de **legalidade**, e não de constitucionalidade”. [26](#)

■ 4.5.3.4. Territórios Federais: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?

Não.

Os **Territórios Federais** (que, como veremos, hoje não mais existem, mas poderão vir a ser criados), de acordo com o art. 18, § 2.º, integram a União, **não** se falando em autonomia federativa, e, portanto, **não se cogitando em manifestação de poder constituinte derivado decorrente**. Trata-se de descentralização administrativo-territorial da União, com natureza jurídica de autarquia federal.

Por todo o exposto, devemos concluir que o **poder constituinte derivado decorrente** (para aqueles que aceitam caracterizá-lo como *constituente* — vide comentário de Celso Bastos em nota anterior) é **apenas** o poder que os Estados-Membros, por meio das Assembleias Legislativas, têm de elaborar as suas Constituições Estaduais, bem como o Distrito Federal, por meio da Câmara Legislativa, de elaborar a sua Lei Orgânica, devendo, ambas, obedecer aos limites impostos pela Constituição Federal, nos exatos termos dos arts. 25, *caput*, e 32, *caput*, da CF/88. [27](#)

Essa particularidade, contudo, não se estende aos Municípios, como visto acima, e muito menos aos Territórios Federais que eventualmente venham a ser criados.

■ 4.5.4. Poder constituinte derivado revisor

O **poder constituinte derivado revisor**, assim como o reformador e o decorrente, é fruto do trabalho de criação do originário, estando, portanto, a ele **vinculado**. É, ainda, um “poder” **condicionado** e **limitado** às regras instituídas pelo originário, sendo, assim, um **poder jurídico**.

Como advertimos, melhor seria a utilização da nomenclatura **competência de revisão**, na medida em que não se trata, necessariamente, de um “poder”, uma vez que o processo de revisão está limitado por uma força maior que é o poder

constituente originário, este sim um verdadeiro poder, inicial e ilimitado, totalmente autônomo do ponto de vista jurídico.

O art. 3.º do ADCT determinou que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional, em **sessão unicameral**.

Instituiu-se um particular **procedimento simplificado** de alteração do texto constitucional, excepcionando a regra geral das PECs, que exige aprovação por 3/5 dos votos dos membros **de cada Casa**, e obedecendo, assim, às regras da bicameralidade (art. 60, § 2.º).

O procedimento da revisão foi disciplinado na **Resolução n. 1-RCF**, do Congresso Nacional, de 18.11.1993 (alterada pela *Res. n. 2, de 1993-RCF*, e pela *Res. n. 1, de 1994-RCF*), que dispôs sobre o *funcionamento dos trabalhos de revisão constitucional*.

O art. 3.º do ADCT introduziu verdadeira competência de revisão para “atualizar” e adequar a Constituição às realidades que a sociedade apontasse como necessárias, **não estando a aludida revisão vinculada ao resultado do plebiscito do art. 2.º do ADCT** (que admitia a volta à monarquia e ao parlamentarismo).

Como o próprio texto constitucional prescreve, após 5 anos, contados de 05.10.1988, seria realizada uma **revisão** na Constituição. Desde já observamos que referida revisão constitucional deveria dar-se após, pelo menos, 5 anos, podendo ser 6, 7, 8... e apenas **uma única vez**, sendo impossível uma segunda produção de efeitos.

Em se tratando de manifestação de um “poder” derivado, os limites foram estabelecidos pelo poder constituinte originário. Muito se questionou a respeito da amplitude desses limites. Teorias surgiram apontando uma ilimitação total; outras apontando a condicionalidade da produção da revisão desde que o plebiscito previsto no art. 2.º do ADCT modificasse a forma ou sistema de governo. A teoria que prevaleceu foi a que fixou como limite material o mesmo determinado ao poder constituinte derivado reformador, qual seja, o limite material fixado nas “cláusulas pé-

treas” do art. 60, § 4.º, da CF/88, vale lembrar, a proibição de emendas tendentes a abolir:

- a forma federativa de Estado;
- o voto direto, secreto, universal e periódico;
- a separação dos Poderes;
- os direitos e garantias individuais.

Nesse sentido, o art. 4.º, § 3.º, da referida *Resolução n. 1-RCF* determinou ser vedada a apresentação de propostas revisionais que:

- incidam na proibição constante do § 4.º do art. 60 da Constituição (as já comentadas cláusulas pétreas);
- substituam integralmente a Constituição;
- digam respeito a mais de um dispositivo, a não ser que se trate de modificações correlatas;
- contrariem a forma republicana de Estado e o sistema presidencialista de governo.

Interessante notar que a *Resolução n. 1-RCF* (art. 4.º, I e II, e §§ 4.º e 5.º), diferentemente do art. 60, I, II e III, da CF/88, dispôs sobre a possibilidade de oferecimento de propostas revisionais:

- por qualquer congressista;
- por representação partidária com assento no Congresso Nacional, por meio de líder;
- pelas Assembleias Legislativas de 3 ou mais Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus membros;
- pela apresentação de proposta revisional popular, desde que subscrita por 15.000 ou mais eleitores, em listas organizadas por, no mínimo, 3 entidades associativas legalmente constituídas, que se responsabilizaram pela idoneidade das assinaturas, obedecidas condições fixadas na *resolução*.

Ainda, não obstante o **procedimento simplificado** prescrito no art. 3.º do ADCT (*quorum* da **maioria absoluta** e **sessão unicameral**, ou seja, os deputados e senadores, durante a revisão, passam a ser tratados, sem qualquer distinção, como **congressistas revisores**), o art. 13 da *Resolução n. 1-RCF* estabeleceu a votação das matérias em **2 turnos**.

No ordenamento jurídico pátrio, a *competência revisional* do art. 3.º do ADCT proporcionou a elaboração de meras 6 Emendas Constitucionais de Revisão (n. 1, de 1.º.03.1994 — *DOU*, 02.03.1994 —, e as de ns. 2 a 6, de 07.06.1994, publicadas no *DOU* em 09.06.1994), não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da **eficácia exaurida** e **aplicabilidade esgotada** da aludida regra.

Todo esse entendimento foi corroborado pelo STF, destacando-se o seguinte julgado:

“EMENTA: (...). **Emenda** ou **revisão**, como processos de mudança na Constituição, são manifestações do poder constituinte **instituído** e, por sua natureza, **limitado**. Está a ‘revisão’ prevista no art. 3.º do ADCT de 1988 sujeita aos **limites estabelecidos no § 4.º e seus incisos do art. 60 da Constituição**. O resultado do **plebiscito** de 21 de abril de 1993 **não tornou sem objeto a revisão** a que se refere o art. 3.º do ADCT. Após 5 de outubro de 1993, cabia ao **Congresso Nacional** deliberar no sentido da **oportunidade** ou **necessidade** de proceder à aludida revisão constitucional, a ser feita ‘**uma só vez**’. As mudanças na Constituição, decorrentes da ‘revisão’ do art. 3.º do ADCT, estão sujeitas ao **controle judicial**, diante das ‘**cláusulas pétreas**’ consignadas no art. 60, § 4.º e seus incisos, da Lei Magna de 1988” (**ADI 981-MC**, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17.03.1993, Plenário, *DJ* de 05.08.1994).

■ 4.6. PODER CONSTITUINTE DIFUSO

O **poder constituinte difuso** [28](#) pode ser caracterizado como um **poder de fato** e que serve de **fundamento** para os mecanismos de atuação da **mutação constitucional** (tema estudado no *capítulo 3*, sobre *hermenêutica*). [29](#)

Se por um lado a mudança implementada pelo *poder constituinte derivado reformador* se verifica de modo formal, palpável, por intermédio das emendas à Constituição, a modificação produzida pelo **poder constituinte difuso** se instrumentaliza de modo **informal** e **espontâneo**, como verdadeiro **poder de fato**, e que decorre dos fatores sociais, políticos e econômicos, encontrando-se em estado de latência. Trata-se de **processo informal de mudança da Constituição**, alterando-se o seu **sentido interpretativo**, e **não o seu texto**, que permanece intacto e com a mesma literalidade.

Nesse sentido, anota Anna Cândida da Cunha Ferraz, “tais alterações constitucionais, operadas fora das modalidades organizadas de exercício do poder constituinte instituído ou derivado, justificam-se e têm fundamento jurídico: são, em realidade, obra ou manifestação de uma espécie inorganizada do poder constituinte, o chamado *poder constituinte difuso*, na feliz expressão de **Burdeau**”.³⁰ E continua: “destina-se a função constituinte difusa a completar a Constituição, a preencher vazios constitucionais, a continuar a obra do Constituinte. Decorre diretamente da Constituição, isto é, o seu fundamento flui da Lei Fundamental, ainda que implicitamente, e de modo difuso e inorganizado”.³¹

Nesses mesmos termos, conclui Barroso que “além do poder constituinte originário e do poder de reforma constitucional existe uma terceira modalidade de poder constituinte: o que se exerce em **caráter permanente**, por **mecanismos informais**, não expressamente previstos na Constituição, mas indubitavelmente por ela admitidos, como são a **interpretação de suas normas** e o **desenvolvimento dos costumes constitucionais**. Essa terceira via já foi denominada por célebre publicista francês *poder constituinte difuso*, cuja titularidade remanesce no povo, mas que acaba sendo exercido por via representativa pelos órgãos do poder constituído, em sintonia com as demandas e sentimentos sociais, assim como em casos de necessidade de afirmação de certos direitos fundamentais”.³²

Mendes, Coelho e Branco constataam que, “... por vezes, em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de

uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade, a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma. O **texto é o mesmo**, mas o **sentido** que lhe é atribuído é **outro**. Como a norma não se confunde com o texto, repara-se, aí, uma **mudança da norma, mantido o texto**. Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação constitucional”.³³

Naturalmente, a mutação e a nova interpretação não poderão macular os **princípios estruturantes** da Constituição, sob pena de se caracterizar inaceitável interpretação inconstitucional e, portanto, combatida mutação inconstitucional.

■ 4.7. PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL

O **poder constituinte supranacional**³⁴ busca a sua fonte de validade na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e em um conceito remodelado de soberania.³⁵

Segundo Maurício Andreiuolo Rodrigues, agindo de fora para dentro, o poder constituinte supranacional busca estabelecer uma Constituição supranacional legítima: “faz as vezes do poder constituinte porque cria uma ordem jurídica de cunho constitucional, na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos Estados ou adere ao direito comunitário de viés supranacional por excelência, com capacidade, inclusive, para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. Da mesma forma, e em segundo lugar, é supranacional, porque se distingue do ordenamento positivo interno assim como do direito internacional”.³⁶

Em interessante estudo, Marcelo Neves demonstra a tendência mundial de superação do “constitucionalismo provinciano ou paroquial pelo **transconstitucionalismo**”, mais adequado para solução dos problemas de direitos fundamentais ou humanos e de organização legítima de poder.³⁷

Não há dúvida de que o tema terá de ser aprofundado e repensado, especialmente diante dessa tendência de **globalização do direito**

constitucional, chegando alguns autores, como Canotilho (com base em Lucas Pires), a sugerir, inclusive, a formulação da denominada **teoria da interconstitucionalidade**, na busca de estudar “as relações interconstitucionais, ou seja, a concorrência, convergência, justaposição e conflito de várias constituições e de vários poderes constituintes no mesmo espaço político”.³⁸

Analisando a União Europeia, Souza Neto e Sarmento vislumbram “(...) um processo de ‘constitucionalização’ do Direito Comunitário europeu, pelo qual este vem ganhando características *sui generis*, que se aproximam daquelas tradicionalmente atribuídas às constituições estatais. Porém, não há como vislumbrar, pelo menos até o momento, a existência de um verdadeiro poder constituinte europeu, sobretudo no sentido de democrático, de um poder constituinte do povo”.³⁹

■ 4.8. NOVA CONSTITUIÇÃO E ORDEM JURÍDICA ANTERIOR

Após estudarmos o tema do Poder Constituinte, devemos analisar o que acontece com as normas que foram produzidas na vigência da Constituição anterior com o advento de uma nova Constituição, um novo Estado. Elas são revogadas? Perdem a validade? Devem ser novamente editadas?

Estamos diante de um dos temas mais fascinantes do direito, qual seja, o do **direito intertemporal *lato sensu***, vale dizer, a relação do direito com **passado, presente e futuro**. Aponta Carlyle Popp que sua importância social reside no tocante à “*segurança dos cidadãos no que concerne ao passado ... O respeito ao direito adquirido, com a consequente proibição da retroatividade da norma legal, é um verdadeiro instrumento de paz social, impeditivo do arbítrio e do abuso de poder por parte do detentor deste*”.⁴⁰

Nesse sentido, enfatizando o possível arbítrio, o abuso dos governantes, assinala Pontes de Miranda que “*a irretroatividade defende o povo; a retroatividade expõe-no à prepotência*”.⁴¹

■ 4.8.1. Recepção

O que acontecerá com as normas infraconstitucionais elaboradas antes do advento da nova constituição?

Todas as normas que forem incompatíveis com a nova Constituição serão **revogadas**, por **ausência de recepção**. Vale dizer, *a contrario sensu*, a norma infraconstitucional que não contrariar a nova ordem será **recepcionada**, podendo, inclusive, adquirir uma nova “roupagem”. Como exemplo lembramos o CTN (Código Tributário Nacional — Lei n. 5.172/66), que, embora tenha sido elaborado com *quorum* de lei ordinária, foi recepcionado pela nova ordem como lei complementar, sendo que os ditames que tratam das matérias previstas no art. 146, I, II e III, da CF só poderão ser alterados por lei complementar.

Pode-se afirmar, então, que, nos casos de normas infraconstitucionais produzidas antes da nova Constituição, incompatíveis com as novas regras, não se observará qualquer situação de inconstitucionalidade, mas, apenas, como vimos, de **revogação** da lei anterior pela nova Constituição, por falta de **recepção**.

Nessa situação, acrescente-se, inadmite-se a realização de controle de constitucionalidade via ação direta de inconstitucionalidade genérica, por falta de previsão no art. 102, I, “a”, da CF/88, permitindo-se, apenas, a possibilidade de se alegar que a norma não foi recepcionada. Deve-se destacar, desde já, contudo, que, apesar de não ser cabível o aludido controle de constitucionalidade concentrado pela via da ação direta de inconstitucionalidade genérica, será perfeitamente cabível a **arguição de descumprimento de preceito fundamental**, introduzida pela Lei n. 9.882, de 03.12.1999, que, regulamentando o art. 102, § 1.º, da CF/88, alterou, profundamente, a sistemática de controle.⁴²

Para ilustrar, pedimos vênias para transcrever jurisprudência do STF que, de maneira precisa, sedimenta o exposto acima:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade — Impugnação de ato estatal editado anteriormente à vigência da CF/88 — Inconstitucionalidade superveniente — Inocorrência — **Hipótese de revogação do ato hierarquicamente inferior por ausência de recepção** — Impossibilidade

de instauração do controle normativo abstrato — Ação direta não conhecida. *A ação direta de inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do poder público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição* sob cuja égide foi instaurado o controle normativo abstrato. A fiscalização concentrada de constitucionalidade supõe a necessária existência de uma relação de contemporaneidade entre o ato estatal impugnado e a carta política sob cujo domínio normativo veio ele a ser editado. O entendimento de que leis pré-constitucionais não se dispõem, vigente uma nova Constituição, à tutela jurisdicional de constitucionalidade *in abstracto* — orientação jurisprudencial já consagrada no regime anterior (RTJ 95/980 — 95/993 — 99/544) — foi reafirmado por esta Corte, em recentes pronunciamentos, na perspectiva da Carta Federal de 1988. A incompatibilidade vertical superveniente de atos do Poder Público, em face de um novo ordenamento constitucional, traduz hipótese de pura e simples **revogação** dessas espécies jurídicas, posto que lhe são hierarquicamente inferiores. *O exame da revogação de leis ou atos normativos do Poder Público constitui matéria absolutamente estranha à função jurídico-processual da ação direta de inconstitucionalidade*” (ADIQO-7/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 04.09.1992, p. 14087, *Ement.* v. 01674-01, p. 1 — original sem grifos).

■ 4.8.1.1. Inconstitucionalidade superveniente?

Por todo o exposto, fica claro que o STF **não** admite a **teoria da inconstitucionalidade superveniente** de ato normativo produzido antes da nova Constituição e perante o novo paradigma.

Nesse caso, ou se fala em **compatibilidade** e aí haverá **recepção**, ou em revogação por **inexistência de recepção**.

Estamos diante do denominado **princípio da contemporaneidade**, ou seja, uma lei só é constitucional perante o paradigma de confronto em relação ao qual ela foi produzida.

■ **4.8.1.2. Uma lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada, mas que, até o advento da nova Constituição, nunca fora objeto de controle de constitucionalidade, poderá ser recebida pela nova Constituição se com ela for compatível?**

A questão, pela primeira vez, foi objeto de pergunta no concurso público da PFN (2005/2006-ESAF), gerando muita discussão. Apareceu, também, em outros momentos como, para se ter um exemplo, em certame elaborado pelo CESP/UnB no concurso de Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados de 2014 (*vide item 4.10.2*).

No entender de parte da doutrina, se a lei produzida antes de 1988 ainda não tivesse sido declarada inconstitucional na vigência do antigo ordenamento, teoricamente, como ela se presume constitucional, poderia ser recebida pelo novo ordenamento se com ele fosse compatível do ponto de vista meramente material.

Contudo, parece-nos que o Judiciário, ao fazer a análise da recepção, terá de verificar, também, se a lei que pretende ser recebida pelo novo ordenamento era compatível, não só do ponto de vista **formal**, como, também, **material**, com a Constituição sob cuja regência foi editada.

Sobre esse tema, assinala Paulo G. G. Branco: “uma vez que vigora o princípio de que, em tese, a inconstitucionalidade gera a nulidade — absoluta — da lei, uma norma na situação em tela já era nula desde quando editada, pouco importando a compatibilidade material com a nova Constituição, que não revigora diplomas nulos”.⁴³

Trata-se, como se verificou, do **princípio da contemporaneidade**, e a lei que nasceu “maculada” possui **vício congênito**, insanável, impossível de ser corrigido pelo fenômeno da recepção. O vício *ab origine* nulifica a lei, tornando-a ineficaz ou írrita.

Como exemplo, podemos citar a discussão sobre a possibilidade de Decreto-lei dispor sobre o regime do PIS no **ordenamento jurídico anterior** (Constituição Federal de 1967/69).

Conforme decidiu o STF, no regime anterior (sendo diferente a regra perante o texto de 1988, que nem mais prevê a figura do Decreto-lei e admite que as contribuições já discriminadas no art. 195, I-IV, podem ser regulamentadas por lei ordinária — cf. *item 19.2.5*), referido ato normativo podia dispor sobre normas tributárias.

Todavia, conforme entendeu o STF, como o **PIS**, então, não tinha essa natureza, mas a de **contribuição**, pela regra específica do **regime anterior**, deveria ser regulamentado por lei complementar, concluindo, então, pelo vício formal de sua instituição, pelos Decretos-leis n. 2.445, de 29.06.1988, e 2.449, de 21.07.1988 (lembrando que o novo texto constitucional foi promulgado em outubro/88).

Assim, como havia incompatibilidade formal perante o texto sob cuja regência referidos Decretos-leis foram editados, não se poderia falar em recepção pelo novo ordenamento.

A análise se deu no caso concreto (difuso), no **RE 148.754**, mas sustentamos a possibilidade do uso da **ADPF** para a análise em abstrato de recepção de atos editados antes do novo ordenamento (como se confirmou no julgamento da **ADPF 130**, em 30.04.2009, pela qual o STF declarou que a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) é incompatível com a atual ordem constitucional, tendo, portanto, sido **revogada** pelo novo ordenamento).

Nessa linha de entendimento, uma lei anterior que nasceu inconstitucional não poderia ser “consertada” pela nova Constituição. Não se poderia falar, então, em “constitucionalidade superveniente”.

Podemos concluir, então, que para uma lei ser recebida ela precisa preencher os seguintes requisitos:

- estar em vigor no momento do advento da nova Constituição;
- não ter sido declarada inconstitucional durante a sua vigência no ordenamento anterior;
- ter compatibilidade **formal** e **material** perante a Constituição sob cuja regência ela foi editada (no ordenamento anterior);

- ter compatibilidade somente **material**, pouco importando a compatibilidade formal, com a nova Constituição.

■ 4.8.1.3. **Características conclusivas sobre o fenômeno da recepção**

Diante do acima exposto, podemos estabelecer algumas regras sobre o fenômeno da recepção:

- no fenômeno da recepção, só se analisa a compatibilidade **material** perante a **nova** Constituição;
- a lei, para ser recebida, como vimos no item anterior, contudo, precisa ter compatibilidade **formal** e **material** perante a **Constituição sob cuja regência ela foi editada**;
- como a análise perante o novo ordenamento é somente do ponto de vista material, uma lei pode ter sido editada como ordinária e ser recebida como complementar (“**nova roupagem**”);
- em complemento, um ato normativo que deixe de ter previsão no novo ordenamento também poderá ser **recebido**. É o caso, por exemplo, do decreto-lei, que não mais existe perante o ordenamento de 1988: o Código Penal (DL n. 2.848/40) foi recebido como lei ordinária;
- se incompatível, a lei anterior será **revogada**, não se falando em inconstitucionalidade superveniente;
- nesse caso, a técnica de controle ou é pelo sistema **difuso** ou pelo **concentrado**, mas, neste último caso, **somente** por meio da **ADPF**. Isso porque só se fala em ADI de uma lei editada a partir de 1988 e perante a CF/88 (**princípio da contemporaneidade**);
- é possível, também, uma **mudança de competência federativa para legislar**, ou seja, matéria que era de competência da União pode perfeitamente passar a ser de competência legislativa dos Estados-Membros (como exemplo, citamos a instituição de *região metropolitana* que, na atual Constituição, passou a ser de competência estadual — art. 25, § 3.º, da CF/88. Cf. discussão no *item 7.5.5*);

■ é possível, ainda, a **recepção de somente parte de uma lei**, como um artigo, um parágrafo etc.;

■ a recepção ou a revogação acontecem no momento da **promulgação** do novo texto. Entendemos, contudo, que o STF poderá **modular** os efeitos da decisão, declarando a partir de quando a sua decisão passa a valer. Nesse caso, a aplicação da técnica da modulação poderia se implementar tanto no controle difuso como no controle concentrado por meio da ADPF. [44](#)

■ 4.8.2. Repristinação

Vejamos a situação: uma norma produzida na vigência da CF/46 não é recepcionada pela de 1967, pois incompatível com ela. Promulgada a CF/88, verifica-se que aquela lei, produzida na vigência da CF/46 (que fora revogada — não recepcionada — pela de 1967), em tese poderia ser recepcionada pela CF/88, visto que totalmente compatível com ela. Nessa situação, poderia aquela lei, produzida durante a CF/46, voltar a produzir efeitos? Ou seja, repristinaria? Como regra geral, o Brasil adotou a **impossibilidade do fenômeno da repristinação**, salvo se a nova ordem jurídica expressamente assim se pronunciar.

Nesse sentido, analisemos o posicionamento do STF sobre o assunto:

“EMENTA: Agravo regimental — Não tem razão o agravante. A recepção de lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de **efeito repristinatório**, porque o nosso sistema jurídico, **salvo disposição em contrário, não admite a repristinação** (artigo 2.º, § 3.º, da Lei de Introdução ao Código Civil — atualmente, acrescente-se, nos termos da Lei n. 12.376/2010, *Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro*). Agravo a que se nega provimento” (AGRAG 235.800/RS, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 25.06.1999, p. 16, *Ement.* v. 01956-13, p. 2660, 1.ª Turma — original sem grifos).

■ 4.8.3. Desconstitucionalização

Trata-se do fenômeno pelo qual as normas da Constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem, permanecem em vigor, mas com o *status* de lei infraconstitucional. Ou seja, as normas da Constituição anterior são recepcionadas com o *status* de norma infraconstitucional pela nova ordem.

Fernanda Dias Menezes de Almeida e Anna Cândida da Cunha Ferraz, em trabalho extremamente interessante, observam que, “surgida na França e aceita por juristas como Carré de Malberg, Duguit, Esmein, Jellinek, Carl Schmitt e, entre nós, por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Pontes de Miranda e José Afonso da Silva, a doutrina da desconstitucionalização afirma a possibilidade de sobrevivência de certos dispositivos da Constituição que perde a validade, não, porém, com o caráter de normas constitucionais, e sim como normas ordinárias”.[45](#)

Exposta a doutrina, resta indagar: o fenômeno da desconstitucionalização é verificado no Brasil? Como regra geral, **não!** No entanto, poderá ser percebido quando a nova Constituição, **expressamente**, assim o requerer, tendo em vista ser o poder constituinte originário ilimitado e autônomo, podendo tudo, inclusive prever o aludido fenômeno, mas desde que o faça, como referido, de **maneira inequívoca e expressa**.

Os exemplos trazidos pelas professoras do Largo São Francisco são: **a) Portugal:** art. 292 da Constituição de 1976; **b) Brasil:** dentre outros, o art. 147 da Constituição do Estado de São Paulo de 1967, nos seguintes termos: “consideram-se vigentes, com o caráter de lei ordinária, os artigos da Constituição promulgada em 9 de julho de 1947 que não contrariem esta Constituição”.

■ 4.8.4. Recepção material de normas constitucionais

Fernanda Dias Menezes de Almeida e Anna Cândida da Cunha Ferraz resgataram o fenômeno da **recepção material das normas constitucionais** de

acordo com a doutrina do Professor Jorge Miranda, apontando outra possibilidade além do já mencionado fenômeno da desconstitucionalização: “a da persistência de normas constitucionais anteriores que guardam, se bem que a título secundário, a antiga qualidade de normas constitucionais. Assim, diz o eminente professor (Jorge Miranda — acrescente-se), ‘a par das normas que são direta expressão da nova ideia de Direito e que ficam sendo o núcleo da Constituição formal, perduram, então, por referência a elas, outras normas constitucionais’ (cf. *Manual de direito constitucional*, Coimbra, Coimbra Ed., 1988, t. II, p. 240)”.[46](#)

Como exemplo, também colacionado pelas ilustres professoras, lembramos o art. 34, *caput*, e seu § 1.º, do ADCT da CF/88, que asseguram, expressamente, a continuidade da vigência de artigos da Constituição anterior, com o caráter de norma constitucional, no novo ordenamento jurídico instaurado.[47](#)

Note-se, porém, que referidas normas são recebidas por **prazo certo**, em razão de seu **caráter precário**, características marcantes no fenômeno da **recepção material das normas constitucionais**.

Desde já, porém, há de se observar que pela própria teoria do poder constituinte originário exposta, que rompe por completo com a antiga ordem jurídica, instaurando uma nova, um novo Estado, o fenômeno da **recepção material** só será admitido se **houver expressa manifestação da nova Constituição**; caso contrário, as normas da Constituição anterior, como visto, serão **revogadas**.

Isso porque, explica José Afonso da Silva, está-se diante da regra da **compatibilidade horizontal de normas de mesma hierarquia**. A posterior revoga a anterior, não podendo conviver com aquela simultaneamente, mesmo que não seja com ela incompatível. **A revogação se concretiza com a simples manifestação do poder constituinte originário** (*lex posterior derogat priori*).[48](#)

■ 4.9. PODER CONSTITUINTE E DIREITO ADQUIRIDO. GRAUS DE RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL: MÁXIMO, MÉDIO OU

MÍNIMO?

Para facilitar o estudo do tema, valemo-nos de interessante compilação feita pelo Ministro Moreira Alves na **ADI 493**, ao destacar o magistério de José Carlos de Matos Peixoto:

■ **retroatividade máxima ou restitutória:** a lei ataca fatos consumados. Verifica-se “quando a lei nova prejudica a coisa julgada (sentença irrecorrível) ou os fatos jurídicos já consumados”. Como exemplo, lembramos o art. 96, parágrafo único, da Carta de 1937, que permitia ao Parlamento rever a decisão do STF que declarara a inconstitucionalidade de uma lei;

■ **retroatividade média:** “a lei nova atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela”. Ou seja, a lei nova atinge as prestações vencidas mas ainda não adimplidas. Como exemplo o autor cita uma “lei que diminuísse a taxa de juros e se aplicasse aos já vencidos mas não pagos” (prestação vencida mas ainda não adimplida);

■ **retroatividade mínima, temperada ou mitigada:** “... a lei nova atinge apenas os efeitos dos fatos anteriores, verificados após a data em que ela entra em vigor”. Trata-se de prestações futuras de negócios firmados antes do advento da nova lei.

O STF vem se posicionando no sentido de que as **normas constitucionais** fruto da manifestação do poder constituinte originário têm, por regra geral, **retroatividade mínima**, ou seja, aplicam-se a fatos que venham a acontecer após a sua promulgação, referentes a negócios passados.

Podemos mencionar o art. 7.º, IV, que, ao vedar a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, significou que a nova regra deverá valer para fatos e prestações futuras de negócios celebrados antes de sua vigência (prestações periódicas). Nesse sentido:

“EMENTA: Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7.º da Constituição de 1988. Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os

efeitos futuros de fatos passados (**retroatividade mínima**). Salvo disposição expressa em contrário — e a Constituição pode fazê-lo —, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 140.499/GO, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 09.09.1994, p. 23444).

Como outro exemplo de **retroatividade mínima**, lembramos a nova regra trazida pela EC n. 35/2001, que, dentre outras, acabou com a necessidade de prévia licença da Casa para o processamento dos parlamentares. O STF entendeu que a nova regra que dispensa a prévia autorização tem aplicação imediata, alcançando todos os casos que aguardavam manifestação das Casas, vale dizer, referentes a fatos ocorridos antes do advento da nova emenda constitucional.

Sendo regra, portanto, a **retroatividade mínima**, nada impede que a norma constitucional revolucionária, já que manifestação do poder constituinte originário ilimitado e incondicionado juridicamente, tenha **retroatividade média** ou **máxima**. Para tanto, contudo, deve existir **expresso pedido** na Constituição. Vejamos:

“EMENTA: Foro especial. Prefeito que não o tinha na época do fato que lhe é imputado como crime, estando em curso a ação penal quando da promulgação da atual Constituição que outorgou aos Prefeitos foro especial (art. 29, X, da Constituição Federal). A Constituição tem eficácia imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Para alcançar, porém, hipótese em que, no passado, não havia foro especial **que só foi outorgado quando o réu não mais era Prefeito** — hipótese que configura retroatividade média, por estar tramitando o processo penal —, **seria mister que a Constituição o determinasse expressamente, o que não ocorre no caso**. Por outro lado, não é de aplicar-se sequer o princípio que inspirou a Súmula 394.⁴⁹ Recurso extraordinário não conhecido” (RE 168.618/PR, Rel. Min. Moreira Alves, j. 06.09.1994, 1.^a Turma, *DJ* de 09.06.1995, p. 17260).

Como se percebe, outra coisa seria se, pendente a ação em relação a fato

passado (antes da CF/88), o referido réu ainda fosse Prefeito. Nessa hipótese sim, sem dúvida, deveriam os autos ser remetidos para o TJ local, já que a nova Constituição atingiria a situação atual (estar no cargo de Prefeito), referente a crime praticado no passado.

Assim, podemos esquematizar:

a) as **normas constitucionais**, por regra, têm **retroatividade mínima**, aplicando-se a fatos ocorridos a partir de seu advento, mesmo que relacionados a negócios celebrados no passado — ex.: art. 7.º, IV;

b) é possível a **retroatividade máxima e média** da norma introduzida pelo **constituente originário** desde que haja **expressa previsão**, como é o caso do art. 51 do ADCT da CF/88. Nesse sentido doutrina e jurisprudência afirmam que **não há direito adquirido contra a Constituição**;

c) por outro lado, as Constituições Estaduais (**poder constituinte derivado decorrente** — limitado juridicamente) e demais dispositivos legais, vale dizer, as **leis infraconstitucionais**, bem como as **emendas à Constituição** (fruto do **poder constituinte derivado reformador**, também limitado juridicamente), estão sujeitos à observância do princípio constitucional da irretroatividade da lei (**retroatividade mínima**) (art. 5.º, XXXVI — “lei” em sentido amplo), com pequenas exceções, como a regra da lei penal nova que beneficia o réu (nesse sentido, cf. AI 292.979-ED, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 19.12.2002). [50](#)

■ 4.10. QUESTÕES

■ 4.10.1. Poder constituinte

1. Todos sabem que o poder constituinte derivado se manifesta através de emendas constitucionais. Isso posto, aprovada a emenda constitucional, ingressando ela no ordenamento jurídico, qual será a sua posição hierárquica em relação às normas constitucionais originárias?

2. comparar o poder constituinte derivado reformador e o revisor.

3. (Notário/SP/2006) Assinale a alternativa correta. A elaboração de uma nova Constituição é da competência do denominado Poder Constituinte Originário. São formas de exercício do Poder Constituinte:

- a) o poder Constituído e o Conselho de Notáveis.
- b) a revolução e a Assembleia Constituinte.
- c) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
- d) os representantes da Sociedade Civil e do Congresso Nacional.

4. (DP/SP/2007 — FCC) Em relação ao poder constituinte originário, pode-se afirmar:

- a) Envolve processos cognitivos e questões complexas sobre teoria política, filosofia, ciência política e teoria da Constituição, já que dispõe, de maneira derivada, sobre a principal lei de um Estado, sua organização e os direitos e garantias fundamentais.
- b) Os positivistas admitem que é um poder de direito que se funda num poder natural, do qual resultam regras anteriores ao direito positivo e decorrentes da natureza humana e da própria ideia de justiça da comunidade.
- c) Sua teorização precedeu historicamente a primeira Constituição escrita, tendo como grande colaborador a figura do abade Emmanuel de Sieyès que alguns meses antes da Revolução Francesa publicou um panfleto intitulado “A Essência da Constituição”.
- d) Sua atividade se dá nos casos de necessária evolução constitucional, onde o texto poderá ser modificado através de regras e limites jurídicos contidos na norma hipotética fundamental idealizada por Hans Kelsen.
- e) Na sua atuação poderá encontrar implicações circunstanciais impositivas como por exemplo as pressões econômicas, sociais e de grupos particulares, mas fundará sua legitimidade numa pauta advinda da ideia de direito da comunidade e de sua tradição cultural.

5. (Procurador/DF-2007 — ESAF) Acerca do poder constituinte, da reforma da Constituição, das cláusulas pétreas, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, assinale a opção correta.

- a) Não há limites para a ação do poder constituinte originário.
- b) A característica da superioridade do poder constituinte originário deriva do fato de este ser anterior a todas as outras manifestações de poder em um Estado.

- c) O exercício do poder constituinte derivado, ou poder constituído, sofre limitações de ordem circunstancial, material, processual e temporal, das quais algumas podem ser implícitas.
- d) Considere a seguinte situação hipotética. Um cidadão firma contrato de mútuo com uma empresa, na vigência de lei que permite a penhora de determinados bens, em caso de inadimplemento da dívida. Posteriormente, entra em vigor nova lei, que passa a classificar como impenhoráveis alguns daqueles bens. Nesse caso, se o mutuário vier a ser executado, poderão ser penhorados todos os bens admitidos pela lei vigente quando da formação do contrato.
- e) Por ser integrante da Constituição, a norma constitucional que enumera as cláusulas pétreas, também chamadas de cláusulas de inamovibilidade, é passível de alteração como outros dispositivos constitucionais. Desse modo, é juridicamente possível a aprovação de emenda constitucional que altere o rol daquelas cláusulas.

6. (Delegado de Polícia/PB — CESPE/UnB — 2009) Quer o poder constituinte formal, quer o poder constituinte material são limitados pelas estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais dominantes da sociedade, bem como pelos valores ideológicos de que são portadores. Marcelo Rebelo Sousa. Direito constitucional. Braga, 1979, p. 62 (adaptada). Considerando o texto acima, assinale a opção correta acerca do poder constituinte:

O poder constituinte formal não se confunde com o poder constituinte material. Este é o poder de autoconformação do Estado segundo certa ideia de direito, enquanto aquele é o poder de decretação de normas com a forma e a força jurídica próprias das normas constitucionais. Em outras palavras, enquanto o poder constituinte material tem por fim qualificar como constitucional determinadas matérias, o formal atribui a essa escolha uma força constitucional.

7. (Defensoria Pública/MG — FUMARC/2009) O princípio constitucional sensível deve, em termos normativos:

- a) Estar enumerado, expressamente, no texto constitucional.
- b) Ser inserido, de forma implícita, na Constituição.
- c) Jamais ensejar intervenção federal ou estadual.
- d) Provocar silêncio dos poderes instituídos.
- e) Provocar silêncio da opinião pública.

8. (6.º Concurso Público — Outorga de Delegações de Notas e de Registros — TJ SP/2009) O poder constituinte atribuído aos Estados-membros para se auto-organizarem é denominado:

- a) decorrente.
- b) originário.
- c) originário-derivado.
- d) originário-federativo.

9. (AFRFB/2005 — ESAF) Sobre o poder constituinte, marque a única opção correta.

- a) A impossibilidade de alteração da sua própria titularidade é uma limitação material implícita do poder constituinte derivado.
- b) A existência de cláusulas pétreas, na Constituição brasileira de 1988, está relacionada com a característica de condicionado do poder constituinte derivado.
- c) Como a titularidade da soberania se confunde com a titularidade do poder constituinte, no caso brasileiro, a titularidade do poder constituinte originário é do Estado, uma vez que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
- d) A impossibilidade de a Constituição Federal ser emendada na vigência de estado de defesa se constitui em uma limitação material explícita ao poder constituinte derivado.
- e) O poder constituinte originário é inicial porque não sofre restrição de nenhuma limitação imposta por norma de direito positivo anterior.

10. (AGU — CESPE/UnB-2010) Julgue o item subsequente, relativo ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade no Brasil.

No que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente jusnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica.

11. (Procurador do MP junto ao TC do Estado/RO — FCC/2010) O Poder Constituinte Reformador, no Brasil:

- a) é fundamento de validade para que os Estados-membros da Federação promulguem Constituições próprias com a aprovação das respectivas Assembleias Legislativas;
- b) permite que a Constituição Federal seja emendada, por meio de revisão constitucional, desde que haja o voto favorável de três quintos de Deputados e Senadores, em sessão unicameral;
- c) está materialmente limitado à forma federativa de Estado, à separação de poderes, à

forma republicana, ao sistema presidencialista, bem como aos direitos e garantias fundamentais segundo disposição expressa do texto constitucional;

- d) pode se manifestar por meio de emendas à Constituição, cujo projeto pode ser proposto por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros;
- e) é caracterizado como derivado, limitado, circunstanciado e inicial.

12. (Advogado/AGU — CESPE/UnB/2009) O poder constituinte originário esgota-se quando é editada uma Constituição, razão pela qual, além de ser inicial, incondicionado e ilimitado, ele se caracteriza pela temporariedade.

13. (Analista de Controle Externo/TCU — Todas as Áreas — CESPE/UnB/2007) A respeito do poder constituinte de reforma, julgue o item subsequente.

O poder de reforma recebe, doutrinariamente, as mais diferentes denominações, sendo seus sinônimos as expressões poder constituinte derivado ou poder constituinte de segundo grau.

14. (Oficial Técnico de Inteligência — ABIN — Direito — CESPE/UnB/2010) A revisão constitucional realizada em 1993, prevista no ADCT, é considerada norma constitucional de eficácia exaurida e de aplicabilidade esgotada, não estando sujeita à incidência do poder reformador.

15. (Analista Judiciário — TRE-PE — Área Judiciária — FCC/2011) O Poder Constituinte derivado decorrente consiste:

- a) no estabelecimento da primeira Constituição de um novo país;
- b) na possibilidade de alterar-se o texto constitucional do país, respeitando-se a regulamentação especial prevista na própria Constituição Federal;
- c) na possibilidade dos Estados-membros de se auto-organizarem através de suas Constituições Estaduais próprias, respeitando as regras limitativas da Constituição Federal;
- d) no estabelecimento de uma Constituição posterior de um velho país;
- e) no fato de não estar sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar a sua vontade.

16. (TJ/CE — Titular de Serviços de Notas e de Registros — IESES/2011) Leia atentamente as proposições abaixo e assinale “certo” ou “errado” (obs.: adaptada pelo autor, na medida em que a prova é de múltipla escolha, com 4 alternativas):

- I) O poder constituinte inicial, por romper completamente com a ordem jurídica anterior, é ilimitado, absoluto e arbitrário.
- II) A elaboração da Lei Orgânica, pelo Município, pode ser considerada verdadeira manifestação do poder constituinte decorrente, também conferido aos Estados-Membros da Federação.
- III) O sistema constitucional vigente criou a figura do poder constituinte derivado revisor, cuja manifestação, prevista no art. 3.º do ADCT, deve ocorrer a cada dez anos, visando manter atual o texto da Constituição.

17. (Promotor de Justiça/MP/RR — CESPE/UnB/2008) Um fazendeiro que detenha a propriedade de nascente de água desde setembro de 1988 pode invocar direito adquirido contra a norma constitucional, oriunda do poder constituinte originário, que estabeleceu a dominialidade pública dos recursos hídricos.

18. (Analista de Correios — Advogado — CESPE/UnB/2011) Julgue o item que se segue, referente a poder constituinte originário e derivado:

O poder constituinte originário, por ser aquele que instaura uma nova ordem jurídica, exige deliberação da representação popular, razão pela qual não se admite a outorga como forma de sua expressão.

19. (Analista — MP/SE — Direito — FCC/2010) O processo formal de mudança das Constituições rígidas, por meio da atuação do poder constituinte derivado, com a aprovação de emendas constitucionais, segundo os procedimentos estabelecidos na própria Constituição pelo legislador constituinte originário, é próprio

- a) da revisão constitucional e da mutação constitucional.
- b) da mutação constitucional e da reforma constitucional.
- c) da reforma constitucional e da revisão constitucional.
- d) da mutação constitucional e do poder constituinte derivado decorrente.
- e) do poder constituinte derivado reformador e da mutação constitucional.

20. (Defensor Público/RS — FCC/2011) No que se refere ao Poder Constituinte, é INCORRETO afirmar:

- a) O Poder Constituinte genuíno estabelece a Constituição de um novo Estado, organizando-o e criando os poderes que o regerão.
- b) Existe Poder Constituinte na elaboração de qualquer Constituição, seja ela a primeira

Constituição de um país, seja na elaboração de qualquer Constituição posterior.

- c) O Poder Constituinte derivado decorre de uma regra jurídica constitucional, é ilimitado, subordinado e condicionado.
- d) Quando os Estados-Federados, em razão de sua autonomia político-administrativa e respeitando as regras estabelecidas na Constituição Federal, auto-organizam-se por meio de suas constituições estaduais estão exercitando o chamado Poder Constituinte derivado decorrente.
- e) Para parte da doutrina, a titularidade do Poder Constituinte pertence ao povo, que, entretanto, não detém a titularidade do exercício do poder.

21. (Magistratura/TRF1 — CESPE/UnB/2009) Julgue os itens subsequentes, relativos aos poderes constituintes originário e derivado. Estão certos apenas os itens:

- I. O poder constituinte originário não se esgota quando se edita uma constituição, razão pela qual é considerado um poder permanente.
- II. Respeitados os princípios estruturantes, é possível a ocorrência de mudanças na constituição, sem alteração em seu texto, pela atuação do denominado poder constituinte difuso.
- III. O STF admite a teoria da inconstitucionalidade superveniente de ato normativo editado antes da nova constituição e perante o novo paradigma estabelecido.
- IV. Pelo critério jurídico-formal, a manifestação do poder constituinte derivado decorrente mantém-se adstrita à atuação dos estados-membros para a elaboração de suas respectivas constituições, não se estendendo ao DF e aos municípios, que se organizam mediante lei orgânica.
- V. O poder constituinte originário pode autorizar a incidência do fenômeno da desconstitucionalização, segundo o qual as normas da constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem constitucional, permanecem em vigor com *status* de norma infraconstitucional.

- a) I e V.
- b) II e III.
- c) I, III e IV.
- d) I, II, IV e V.
- e) II, III, IV e V.

22. (Analista Administrativo — ANATEL — Direito — CESPE/UnB/2009) Mutações constitucionais são alterações no texto da CF decorrentes de novos cenários na ordem econômica, social e cultural do país.

23. (Defensor Público/BA — CESPE/UnB/2010) O denominado poder constituinte supranacional tem capacidade para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo, distinguindo-se do ordenamento jurídico positivo interno assim como do direito internacional.

24. (Juiz do Trabalho — TRT 23R — MT — 2012) Analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

- I. O poder constituinte derivado revisor é condicionado e limitado às regras instituídas pelo poder originário.
 - II. O poder constituinte difuso é um processo formal de mudança da Constituição, com a alteração da interpretação como consequência da modificação do texto da norma.
 - III. Para que uma lei seja recepcionada pela nova Constituição é indispensável que haja compatibilidade formal e material.
 - IV. Pela teoria da desconstitucionalização, ainda que compatíveis com a nova ordem, as normas da Constituição anterior não podem ser recepcionadas com *status* de norma infraconstitucional.
 - V. O poder constituinte de segundo grau sofre limitações formais ou procedimentais, circunstanciais e materiais.
- a) Apenas as proposições I e III estão corretas e as demais estão incorretas.
 - b) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
 - c) Apenas as proposições I, III e V estão corretas e as demais incorretas.
 - d) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.
 - e) Todas as proposições estão corretas.

25. (MPSP — 2012 — Prova oral) O que é poder constituinte difuso?

26. (Defensoria Pública/SP — V Concurso — FCC/2012) Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), um dos inspiradores da Revolução Francesa, foi autor de um texto que teve grande repercussão na teoria do Poder Constituinte. O referido texto é:

- a) *Que é o terceiro Estado?*
- b) *O poder do terceiro Estado.*

- c) *Que pretende o terceiro Estado?*
- d) *Que tem sido o terceiro Estado?*
- e) *A importância do terceiro Estado.*

27. (Magistratura do Trabalho — TRT/18.^a Região — FCC/2012) A doutrina do poder constituinte foi elaborada na obra:

- a) *O Espírito das Leis*, de Montesquieu.
- b) *O contrato social*, de Jean Jacques Rousseau.
- c) *Leviatã*, de Thomas Hobbes.
- d) *O que é o terceiro Estado?*, de Emmanuel Joseph Sieyès.
- e) *Segundo Tratado sobre o Governo Civil*, de John Locke.

28. (Defensoria Pública/RO — CESPE/UnB/2012) Assinale a opção correta a respeito do poder constituinte e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão:

- a) Compete ao poder constituinte decorrente elaborar e modificar as constituições dos Estados-membros da Federação.
- b) O poder constituinte reformador é, por característica, incondicionado.
- c) A mutação constitucional é expressão do poder constituinte derivado.
- d) Denomina-se repristinação o fenômeno pelo qual a constituição nova recebe a ordem normativa infraconstitucional anterior, surgida sob égide das constituições precedentes, quando compatível com o novo ordenamento constitucional.
- e) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem por escopo controlar apenas as omissões legislativas.

29. (Analista de Finanças e Controle/CGU — ESAF/2004) Analise a assertiva a seguir, relativa ao poder constituinte e princípios constitucionais, e marque com V se verdadeira e com F se falsa (adaptada — prova original com 5 assertivas):

Segundo precedente do STF, no caso brasileiro, não é admitida a posição doutrinária que sustenta ser o poder constituinte originário limitado por princípios de direito suprapositivo.

30. (Técnico Judiciário — Administrativo/TRT10 — CESPE/UnB/2013) O poder constituinte estadual classifica-se como decorrente, em virtude de consistir em uma criação do poder constituinte originário, não gozando de soberania, mas de autonomia.

31. (Analista Legislativo/CD — Consultor Legislativo Área I — CESPE/UnB/2014) À luz da doutrina atual relativa ao poder constituinte, julgue o item a seguir:

O poder constituinte originário tem o condão de instaurar uma nova ordem jurídica por meio de uma nova constituição ou mesmo de um ato institucional.

32. (Técnico Judiciário — Área Judiciária — TJCE — CESPE/UnB/2014) Julgue o item seguinte em relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

O poder constituinte dos estados, dada a sua condição de ente federativo autônomo, é soberano e ilimitado.

33. (Analista Judiciário — TRE/AM — IBFC/2014) Por “mutação constitucional”, entende-se:

- a) A inserção de emendas constitucionais no texto da Constituição.
- b) A superveniência de uma nova Carta Política.
- c) A nova interpretação dada à Constituição, atribuindo novos sentidos ao seu texto.
- d) O exercício do Poder Derivado Decorrente.

■ 4.10.2. Nova Constituição e ordem jurídica anterior

1. (OAB/107.º) Quando da promulgação de uma nova Constituição, diz-se que a legislação ordinária compatível perde o suporte de validade da Constituição antiga, mas continua válida pela teoria

- a) da repristinação;
- b) da desconstitucionalização;
- c) da recepção;
- d) do poder constituinte subordinado.

2. (MP/RS — XL) O fenômeno que os constitucionalistas de escol chamam de “desconstitucionalização” das normas constitucionais de uma Constituição revogada significa:

- a) que tais normas saíram do mundo jurídico;
- b) que tais normas já não são válidas e eficazes;
- c) que tais normas permanecem no mundo jurídico como ordinárias;

- d) que tais normas repristinaram automaticamente;
- e) nenhuma das alternativas anteriores está correta.

3. (PFN/2006 — ESAF) Considerando o Direito Brasileiro, assinale a opção correta, no que diz respeito às consequências da ação do poder constituinte originário.

- a) Uma lei federal sobre assunto que a nova Constituição entrega à competência privativa dos Municípios fica imediatamente revogada com o advento da nova Carta.
- b) Uma lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada, mas que, até o advento da nova Constituição, nunca fora objeto de controle de constitucionalidade, não é considerada recebida por esta, mesmo que com ela guarde plena compatibilidade material e esteja de acordo com o novo processo legislativo.
- c) Para que a lei anterior à Constituição seja recebida pelo novo Texto Magno, é mister que seja compatível com este, tanto do ponto de vista da forma legislativa como do conteúdo dos seus preceitos.
- d) Normas não recebidas pela nova Constituição são consideradas, ordinariamente, como sofrendo de inconstitucionalidade superveniente.
- e) A doutrina majoritária e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal convergem para afirmar que normas da Constituição anterior ao novo diploma constitucional, que com este não sejam materialmente incompatíveis, são recebidas como normas infraconstitucionais.

4. (TRT/7.ª Região/2006 — ESAF) Assinale a opção correta.

- a) Com o advento de uma nova Constituição, normas da Constituição anterior que sejam compatíveis com o novo diploma continuam a vigorar, embora com força de lei.
- b) Chama-se Constituição outorgada aquela que é votada pelos representantes do povo especialmente convocados para elaborar o novo Estatuto Político.
- c) Normas de lei ordinária anteriores à nova Constituição que sejam com essa materialmente compatíveis são tidas como recebidas, mesmo que se revistam de forma legislativa que já não mais é prevista na nova Carta.
- d) Admite-se pacificamente entre nós a invocação do direito adquirido contra norma provinda do poder constituinte originário.
- e) Assentou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as normas anteriores à Constituição com essa materialmente incompatíveis são consideradas inconstitucionais, e não meramente revogadas.

5. (Auditor — TC/RO — FCC/2010) De acordo com a teoria da recepção, decreto-lei que tenha sido editado sob a égide de Constituição anterior, e compatível, em princípio, com a nova ordem constitucional:

- a) continua válido no ordenamento jurídico e pode ser submetido ao controle de constitucionalidade concentrado por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- b) transforma-se, por mutação constitucional, em lei ordinária e passa a incorporar a nova ordem constitucional com uma nova numeração.
- c) passa a integrar a nova ordem constitucional com hierarquia inferior à lei complementar e à lei ordinária.
- d) insere-se na nova ordem constitucional automaticamente, mas o Supremo Tribunal Federal, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, poderá anular seus efeitos.
- e) incorpora-se à nova ordem constitucional apenas se, por mutação constitucional, transformar-se em decreto legislativo mediante aprovação do Congresso Nacional.

6. (MP/CE — FCC/2008) Sob a Constituição de 1967, determinada matéria cível era objeto de lei ordinária e, de fato, havia lei ordinária sobre ela. Em momento ulterior, sobreveio a Constituição de 1988, que confiou à lei complementar a matéria em causa. Anos depois, sob a nova ordem constitucional, foi promulgada emenda constitucional que recolocou a matéria em questão no campo da lei ordinária. Neste contexto:

- a) após a emenda constitucional não cabe ADPF para discutir eventual inconstitucionalidade material superveniente da legislação anterior reportada em relação à nova Constituição.
- b) a emenda constitucional poderia repristinar a legislação anterior aludida se acaso ela não houvesse sido recepcionada, por questões formais em geral, pela nova Constituição.
- c) as eventuais incongruências materiais havidas entre a nova Constituição e a legislação anterior mencionada são sanadas pela recepção.
- d) cabe ADI para discutir eventual vício formal superveniente, em face da nova Constituição, da legislação anterior citada.
- e) após a emenda constitucional, uma medida provisória pode revogar no todo ou em parte a legislação anterior referida.

7. (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas — Controle Ambiental — SEPLAG/DF

FUNIVERSA/2011) (...) A respeito do poder constituinte aplicado ao caso brasileiro, assinale a alternativa correta:

- a) A Constituição Federal de 1988 foi fruto do poder reformador, tendo sido convocada a sua Assembleia Constituinte por intermédio de Emenda Constitucional à Carta Política então vigente.
- b) Reconhece o Supremo Tribunal Federal que, se uma norma anterior ao texto constitucional não for compatível com a Constituição vigente, há revogação da norma que afronta o Texto Maior, e não caso de inconstitucionalidade superveniente.
- c) É juridicamente inviável sustentar-se a garantia do direito adquirido em face do poder constituinte originário; todavia, em relação à coisa julgada, essa garantia é remansosamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) A Constituição Federal de 1988 determinou, expressamente, a recepção dos diplomas infraconstitucionais anteriores à sua promulgação que, com ela, materialmente não colidiam.
- e) A repristinação de uma norma infraconstitucional, não recebida pelo ordenamento constitucional vigente, poderá ocorrer no caso de uma nova constituição que não se oponha, ainda que implicitamente, àquela norma inferior.

8. (Defensor Público/SP — FCC/2012) A Constituição Federal de 1988, fruto do exercício do Poder Constituinte Originário, inaugurou nova ordem jurídico-constitucional. Sobre o relacionamento da Constituição Federal de 1988 com as ordens jurídicas pretéritas (constitucionais e infraconstitucionais) é correto afirmar:

- a) Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição Federal de 1988, desde que compatíveis material e formalmente com a ordem constitucional atual, continuam válidas.
- b) De acordo com entendimento dominante no STF, os dispositivos da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), que não forem contrários à Constituição Federal de 1988, continuam válidos, mas ocupam posição hierárquica infraconstitucional legal.
- c) Por força de norma expressa do ADCT da Constituição Federal de 1988, houve manutenção da aplicação de determinados dispositivos da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969).
- d) A promulgação da Constituição Federal de 1988 revogou integralmente a Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), inexistindo, dada a incompatibilidade da ordem constitucional atual com o regime ditatorial anterior,

possibilidade de recepção de dispositivos infraconstitucionais.

- e) Dispositivo da Constituição de 1946, que seja plenamente compatível com a ordem constitucional de 1988, com a revogação da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), tem sua validade retomada.

9. (Analista Legislativo/CD — Consultor Legislativo Área I — CESPE/UnB/2014) À luz da doutrina atual relativa ao poder constituinte, julgue o item a seguir:

Com o advento de uma nova ordem constitucional, é possível que dispositivos da constituição anterior permaneçam em vigor com o *status* de leis infraconstitucionais, desde que haja norma constitucional expressa nesse sentido.

10. (Analista Legislativo/CD — Consultor Legislativo Área I — CESPE/UnB/2014) Em relação ao poder constituinte e ao direito intertemporal, julgue o item que se segue:

Considere que lei editada sob a égide de determinada Constituição apresentasse inconstitucionalidade formal, apesar de nunca de ter sido declarada inconstitucional. Nessa situação, com o advento de nova ordem constitucional, a referida lei não poderá ser recepcionada pela nova constituição, ainda que lhe seja materialmente compatível, dado o vício insanável de inconstitucionalidade.

11. (Analista Legislativo/CD — Consultor Legislativo Área I — CESPE/UnB/2014) Em relação ao poder constituinte e ao direito intertemporal, julgue o item que se segue:

Suponha que uma lei infraconstitucional tenha sido revogada pelo advento de uma nova ordem constitucional, por ser com ela incompatível. Nessa situação, com a entrada em vigor de uma terceira ordem constitucional, ainda que seja compatível com ela, a referida lei infraconstitucional não poderá ser restaurada, salvo se houver disposição constitucional expressa nesse sentido.

■ 4.10.3. Graus de retroatividade da norma constitucional

1. (BACEN — CESPE/UnB/2009) Assinale a opção correta acerca de Constituição, hermenêutica constitucional e poder constituinte originário e derivado, no ordenamento jurídico brasileiro (adaptada):

De acordo com entendimento do STF, as normas constitucionais provenientes da

manifestação do poder constituinte originário têm, via de regra, retroatividade máxima.

2. (Profissional Júnior — Direito — Petrobras — CESGRANRIO/2010) Suponha a seguinte situação: em 2007, a BR Distribuidora firmou contrato com empresa privada. Posteriormente, foi promulgada emenda constitucional que afetava obrigações assumidas pela BR Distribuidora relativas ao pagamento mensal dos valores acordados no contrato. Considerando que a emenda constitucional nada dispõe sobre retroatividade, em tal caso, a emenda constitucional:

- a) não é dotada de retroatividade, pois tem vigência imediata, mas afeta apenas as obrigações futuras.
- b) é dotada de retroatividade mínima, pois tem vigência imediata, mas afeta apenas as obrigações futuras.
- c) é dotada de retroatividade média, pois tem vigência imediata, mas afeta apenas as obrigações futuras.
- d) é dotada de retroatividade máxima, pois tem vigência imediata e afeta todas as obrigações contratuais (pagas, pendentes e vincendas).
- e) é dotada de retroatividade máxima, mas não afeta os termos do contrato, que está protegido pelo ato jurídico perfeito.

3. (OAB — Exame de Ordem Unificado 3 — 1.ª Fase — CESPE/UnB/2008) A respeito da entrada em vigor de uma nova ordem constitucional, assinale a opção correta.

- a) Na CF, foi adotada a *vacatio constitutionis* (vacância da Constituição), que corresponde ao interregno entre a publicação do ato de sua promulgação e a data estabelecida para a entrada em vigor de seus dispositivos.
- b) A regra geral de retroatividade máxima das normas constitucionais aplica-se às normas constitucionais federais e estaduais.
- c) No Brasil, os dispositivos de uma constituição nova têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo disposição constitucional expressa em contrário.
- d) A inconstitucionalidade superveniente, regra adotada pelo STF, é o fenômeno jurídico por meio do qual uma norma se torna inconstitucional em momento futuro, depois de sua entrada em vigor, em razão da promulgação de um novo texto constitucional com ela conflitante.

4. (Técnico Jurídico — Apoio Administrativo — PGDF — IADES/2011) Assinale certo

ou errado (questão adaptada pelo autor, já que a pergunta original contém 5 alternativas de múltipla escolha):

Soberanas em relação a qualquer outra norma do ordenamento jurídico, a interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal é de que as normas constitucionais, por regra geral, têm re-
troatividade mínima.

5. (Advogado/Petrobras — CESPE/UnB/2007) Em ação judicial impetrada contra a empresa Gama Ltda., a PETROBRAS S.A. requereu que uma lei de 1990 incidisse retroativamente para atingir contrato de prestação de serviços firmado entre si e a empresa Gama, de modo a fixar novos parâmetros de reajustes de preços, diferentes daqueles que foram originalmente pactuados no contrato. Acerca dessa situação hipotética e dos parâmetros de interpretação constitucional que se devem aplicar quando se discute o ato jurídico perfeito, julgue o item a seguir.

Na hipótese considerada, tem-se um exemplo de retroação, ou seja, uma circunstância em que se pretende aplicar de imediato uma lei nova para alcançar os efeitos futuros de fatos passados. Nesse caso, está-se diante da retroatividade mínima.

■ GABARITO ■

■ 4.10.1. Poder constituinte
1. Desde que não haja qualquer afronta aos limites colocados pelo poder constituinte originário, a norma introduzida por emenda, seja pelo poder constituinte reformador, seja pelo revisor, terá a natureza de norma constitucional, com a mesma força e posição que as normas introduzidas pelo poder constituinte originário. Em igual sentido, artigo de emenda, não introduzido no texto constitucional, também terá natureza constitucional, nos termos da teoria do “bloco de constitucionalidade” (cf. <i>item 6.7.1.3</i>).
2. Apontando as semelhanças, ambos são competências que visam alterar a CF, através da modificação de um artigo já existente, ou mediante supressão, ou mesmo inclusão de um novo artigo no texto constitucional. Em relação às diferenças, lembramos: <i>a)</i> no tocante ao momento de manifestação, o reformador poderá acontecer a qualquer tempo, desde que, é claro, observadas as limitações circunstanciais do art. 60, § 1.º (“ <i>A Constituição não poderá ser emendada na vigência de</i>

*intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio”); enquanto o revisor produziu efeitos após cinco anos contados da promulgação da CF, uma única vez. Assim, a única forma de se alterar hoje a Constituição vigente é por meio de emendas; 51 b) a aprovação de uma *emenda constitucional* dar-se-á de acordo com o art. 60, § 2.º, em dois turnos de votação, em cada Casa, com o quórum de três quintos dos membros de cada Casa; por outro lado, a aprovação das *emendas de revisão* se concretizou pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral; c) as emendas constitucionais são promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o seu respectivo número de ordem; enquanto *as emendas de revisão foram promulgadas* pela Mesa do Congresso Nacional, já que a votação se consolidou em sessão unicameral.*

3. “b”.

4. “e”.

5. “c”. Interessante a alternativa “a” que, de fato, conforme estudado na parte teórica, está errada, em razão da necessidade de a nova Constituição observar, dentre outros, os princípios de justiça, suprapositivos, como aqueles de observância de direitos humanos.

6. Afirmação correta, nos termos da parte teórica, *item 4.4.4*.

7. “a”.

8. “a”.

9. “a”. As limitações expressas ao poder de reforma caracterizam-se como a primeira limitação implícita ou inerente. Outras duas limitações implícitas apontadas pela doutrina são a impossibilidade de se alterar tanto o titular do poder constituinte originário como o titular do poder constituinte derivado reformador. A *letra “b”*, em nossa análise e com o máximo respeito, não deveria ter sido colocada como *errada*, pois, de fato, as cláusulas pétreas, fazendo uma análise mais ampla, são limites materiais ao poder de reforma (poder constituinte derivado reformador e revisor). O poder constituinte derivado está condicionado aos limites colocados pelo originário, daí ser ele constituído, instituído, secundário ou de segundo grau. A *letra “c”* está errada, pois a titularidade do poder constituinte, como aponta a doutrina moderna, pertence ao povo. A *letra “d”* está errada, pois confunde conceitos. De fato, o poder constituinte derivado reformador, que se implementa por meio das emendas à Constituição, sofre diversas modalidades de limites. Dentre os limites ao poder de reforma estão as denominadas limitações circunstanciais, quais sejam, a

impossibilidade de alteração do texto na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio (art. 60, § 1.º). As limitações materiais são as cláusulas pétreas do art. 60, § 4.º. Por fim, a <i>letra “e”</i> está errada, pois definiu a característica de ser o PCO ilimitado juridicamente.
10. “errado”. Apesar de tendências no sentido de flexibilização da ideia de <i>onipotência do poder constituinte</i> , as provas vêm afirmando, de maneira correta, a adoção, pelo Brasil, da corrente positivista, e não jusnaturalista. Está correto afirmar que o poder constituinte originário é ilimitado (juridicamente) e apresenta natureza pré-jurídica.
11. “d”. Cf. art. 60, III.
12. “errado”. Conforme visto, editada a Constituição, o <i>poder constituinte originário</i> permanece “adormecido”, em estado de latência e, assim, pode-se afirmar ser ele permanente, e não temporário.
13. “certo”.
14. “certo”.
15. “c”.
16. O <i>item I</i> está errado, pois não se pode falar que o poder constituinte originário seja absoluto e arbitrário, apesar de ilimitado juridicamente. O <i>item II</i> está errado conforme explicamos no <i>item 4.5.3.2</i> . O <i>item III</i> também está errado, pois o poder de revisão se manifestaria a partir de 5 anos da promulgação do texto e uma única vez, estando, assim, o art. 3.º do ADCT, na medida em que já se pronunciou, com a sua eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada (cf. <i>item 4.5.4</i>).
17. “errado”, na medida em que, por ser ilimitado juridicamente, contra o poder constituinte originário não se pode opor direito adquirido.
18. “errado”. Conforme visto, as formas de expressão do <i>poder constituinte originário</i> são tanto a assembleia nacional constituinte (democrática, popular que promulga o texto) como, também, a combatida situação de outorga, de imposição de maneira unilateral por um agente revolucionário.
19. “c”.
20. “c”, já que o poder de reforma, em sendo subordinado aos limites fixados pelo originário, é limitado juridicamente. Em relação à <i>letra “a”</i> , interessante observar o uso da terminologia poder

constituente genuíno. No caso, trata-se, como visto na parte teórica, do poder constituinte originário, também denominado inicial, inaugural ou de 1.º grau. A <i>letra “b”</i> está perfeita e trata tanto do poder constituinte originário histórico (ou fundacional) como do poder constituinte originário revolucionário. A <i>letra “d”</i> define com precisão o conceito, assim como se encontra correta a <i>letra “e”</i>.
21. “d”. Apenas alerta-se, no tocante ao <i>item IV</i>, como explicitado na parte teórica, que mudamos de posicionamento em relação ao DF, sustentando, com base em doutrina e jurisprudência do STF, que se verifica, sim, a manifestação do <i>poder constituinte derivado decorrente</i>. Assim, o examinador, para aceitar a afirmação do referido item, deverá especificar tratar-se do critério jurídico-formal, expressão, inclusive, por nós lançada na 13.ª ed. e anteriores desta obra.
22. “errada”. A mutação, enquanto <i>processo informal de mudança da Constituição</i>, consiste na mudança do sentido interpretativo da norma, e não do texto, que continua intacto e com a mesma literalidade. Não se confunde com a <i>reforma constitucional</i>, que, por sua vez, altera fisicamente o texto, por meio de emenda constitucional fruto do poder constituinte derivado reformador ou revisor.
23. “certo”. Confira parte teórica.
24. “b”. O <i>item I</i> definiu bem a ideia de limitação jurídica. O <i>item V</i>, conforme visto, ao falar em poder constituinte de segundo grau, refere-se ao poder constituinte derivado (cf. <i>item 4.5</i>), que também é limitado juridicamente. O <i>item II</i> está errado. Já vimos que o <i>poder constituinte difuso</i> se manifesta de modo informal, alterando-se o sentido interpretativo do texto. O <i>item III</i> está errado, já que a compatibilidade perante a nova ordem é meramente material, pouco importando a compatibilidade formal. O <i>item IV</i> erra ao afirmar justamente o contrário do conceito. Conforme se estudou, pela teoria da desconstitucionalização, as normas da Constituição anterior são recepcionadas com o <i>status</i> de lei infraconstitucional e, claro, desde que haja pedido expresso.
25. cf. item 4.6.
26. “a”. Cf. <i>item 4.2</i>.
27. “d”. Cf. <i>item 4.2</i>.
28. “a”. Conforme vimos na parte teórica, estamos diante tanto do poder constituinte decorrente inicial (“instituidor” ou “institucionalizador”), responsável pela elaboração da Constituição estadual,

como do poder constituinte decorrente de revisão estadual (“poder decorrente de segundo grau”), que tem a finalidade de modificar o texto da Constituição estadual (Anna Cândida da Cunha Ferraz).
29. “verdadeira”. “Princípios de direito suprapositivo” deve ser entendido como “princípios de direito natural”. Nesse sentido, contrariando parte da doutrina, a posição do STF, materializada no seguinte <i>leading case</i>: “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos 1.º e 2.º do artigo 45 da Constituição Federal. — A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é impossível com o sistema de Constituição rígida. — Na atual Carta Magna ‘compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição’ (artigo 102, ‘caput’), o que implica dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição” (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, j. 28.03.1996, Plenário, DJ de 10.05.1996).
30. “certo”.
31. “certo”. Cf. parte teórica, <i>item 4.4.1</i> .
32. “errado”.
33. “c”.
■ 4.10.2. Nova Constituição e ordem jurídica anterior
1. “c”.
2. “c”.
3. “b”. A letra “a” estabelece regra mais do que comum, qual seja, mudança de competência legislativa, perfeitamente compatível com o fenômeno da recepção, já que a compatibilidade com a nova Constituição tem de ser meramente material. A letra “b” é a correta, de acordo com a parte teórica (<i>item 4.8.1.2</i>). Apenas alertamos que a parte final era desnecessária, qual seja, guardar compatibilidade formal (estar de acordo com o novo processo legislativo), pois, conforme visto, a análise da compatibilidade perante a nova Constituição é meramente material. A letra “c” está errada, uma vez que a compatibilidade é meramente material, pouco importando a compatibilidade

formal. A letra “d” está errada, pois se a norma não for recebida é porque ela é incompatível. Sendo incompatível do ponto de vista material, será revogada. Por fim, a letra “e” está errada porque o fenômeno descrito da desconstitucionalização não foi adotado como regra no Brasil, e para que ocorra é preciso pedido e manifestação expressa do constituinte originário.
4. “c”. A letra “a” está errada, pois, como visto na questão anterior, ao comentar a letra “e”, para que ocorra o fenômeno da desconstitucionalização, que não é a regra, é necessária manifestação expressa do constituinte originário. A letra “b” é errada porque outorgada é aquela Constituição imposta de maneira unilateral por um agente revolucionário, conforme já estudamos. A letra “c” está perfeita, pois o que se verifica no fenômeno da recepção é a compatibilidade meramente material, pouco importando a compatibilidade formal. A letra “d” está errada, uma vez que, tendo em vista ser o poder constituinte originário ilimitado do ponto de vista jurídico, não se pode a ele opor o direito adquirido (cf. art. 17, ADCT). Por fim, a letra “e” está errada porque as normas anteriores à Constituição com esta materialmente incompatíveis são revogadas por não recepção, tanto é que não se verifica o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente.
5. “a”.
6. “e”, isso porque, a partir da EC, a matéria passou para o campo da lei ordinária, podendo, assim, ser revogada por MP. A letra “a” está errada, pois a ADPF é o instrumento para análise em abstrato de recepção de ato normativo editado antes do novo ordenamento. Apenas uma crítica no sentido de que, embora a análise seja da compatibilidade material, o mais adequado seria falar em recepção ou revogação (se não compatível), e não em “inconstitucionalidade superveniente”. A letra “b” está errada, já que a recepção analisa apenas o critério material, pouco importando a compatibilidade formal. Tanto é, por exemplo, que as normas gerais do CTN, lei ordinária, foram recepcionadas como LC. Assim, não tem sentido falar em incompatibilidade <i>formal</i> para efeito de recepção perante o novo ordenamento. A letra “c” está errada, pois a incongruência material acarreta a revogação do ato normativo e, assim, não terá havido recepção da lei. A letra “d” está errada, pois a análise na recepção é meramente material, e não formal em relação à nova Constituição.
7. “b”.
8. “c”, conforme o art. 34, <i>caput</i>, do ADCT. Seria mais completo se a alternativa tivesse deixado claro que referida recepção material foi por prazo certo e em caráter precário. A letra “a” está errada, na medida em que a compatibilidade a ser observada perante o novo ordenamento jurídico é

meramente material, pouco importando a compatibilidade formal. Além disso, teria sido mais técnico se a alternativa afirmasse que referidos atos seriam recepcionados. A letra “b” está errada, porque o fenômeno da desconstitucionalização não é automático e depende de pedido expresso na nova Constituição, o que não se observa na CF/88. A letra “d” está errada em razão de ser, sim, possível a recepção de atos infraconstitucionais, desde que compatíveis. A letra “e” está errada, pois o fenômeno da repristinação não é automático e depende de previsão expressa na nova Constituição, não tendo sido verificado tal fenômeno na CF/88.
9. “certo”. Trata-se, conforme visto na parte teórica, do fenômeno da desconstitucionalização.
10. “certo”. Cf. parte teórica, <i>item 4.8.1.2</i>.
11. “certo”. Trata-se do fenômeno da repristinação que, de fato, não é automática e necessita de previsão explícita pela nova Constituição.
■ 4.10.3. Graus de retroatividade da norma constitucional
1. Essa alternativa está errada, pois a regra, conforme visto na parte teórica, é no sentido de as normas originárias terem retroatividade mínima, podendo, contudo, desde que haja pedido expresso, apresentar retroatividade média ou máxima (cf. <i>item 4.8</i>).
2. “b”.
3. “c”.
4. “certo”.
5. “certa”. O enunciado não está muito claro. A resposta deve ser dada considerando a alternativa. No enunciado afirma-se que a nova lei retroagiu para atingir “o contrato”, e não fato já consumado (que seria retroatividade máxima) ou efeito jurídico pendente de ato jurídico anterior (que seria retroatividade média). Estabeleceu, ainda, que a nova lei retroagiu para fixar novos parâmetros de reajuste — mas não especificou do quê. Assim, para responder, temos que considerar a <i>alternativa</i> que, no caso, descreve bem o sentido de retroatividade mínima, ou seja, aplicação imediata, alcançando efeitos futuros de fatos passados.

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

■ 5.1. EFICÁCIA JURÍDICA E EFICÁCIA SOCIAL

Como regra geral, todas as normas constitucionais apresentam **eficácia**, algumas **jurídica** e **social** e outras apenas **jurídica**.

Michel Temer observa que a “*eficácia social* se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade para regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. *Eficácia jurídica*, por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência de relações concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam”.¹

As normas constitucionais, segundo José Afonso da Silva, podem ser de eficácia: **plena**, **contida** e **limitada**. Vejamo-las.²

■ 5.2. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA PLENA

Normas constitucionais de **eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral** são aquelas normas da Constituição que, no momento que esta entra em vigor, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional (situação esta que pode ser observada, também, na hipótese de introdução de novos preceitos por emendas à

Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º). Em regra criam órgãos ou atribuem aos entes federativos competências. Não têm a necessidade de ser integradas. Aproximam-se do que a doutrina clássica norte-americana chamou de normas autoaplicáveis (*self-executing*, *self-enforcing* ou *self-acting*).

José Afonso da Silva destaca que as **normas constitucionais de eficácia plena** “... são as que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata. Situam-se predominantemente entre os elementos orgânicos da Constituição. Não necessitam de providência normativa ulterior para sua aplicação. Criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo exigíveis”.³

Como exemplo, lembramos os arts. 2.º; 5.º, III; 14, § 2.º; 16; 17, § 4.º; 19; 20; 21; 22; 24; 28, *caput*; 30; 37, III; 44, parágrafo único; 45, *caput*; 46, § 1.º; 51; 52; 60, § 3.º; 69; 70; 76; 145, § 2.º; 155; 156; 201, §§ 5.º e 6.º (cf. AI 396.695-AgR, *DJ* de 06.02.2004); 226, § 1.º; 230, § 2.º (gratuidade de transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos — cf. ADI 3.768, *DJ* de 26.10.2007), todos da CF/88. Abaixo, pedimos vênias para destacar o importante reconhecimento, pelo STF, da autonomia da Defensoria Pública Estadual, nos termos da *Reforma do Poder Judiciário*:

“Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2.º, inciso IV, ‘c’, da Lei n. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de Pernambuco, que estabelece a vinculação da Defensoria Pública estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: violação do art. 134, § 2.º, da Constituição Federal, com a redação da EC 45/04: inconstitucionalidade declarada. A EC 45/04 outorgou expressamente **autonomia funcional e administrativa** às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2.º): donde, ser **inconstitucional** a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de Estado. A norma de autonomia inscrita no **art. 134, § 2.º**, da Constituição Federal pela EC 45/04 é de **eficácia plena e aplicabilidade imediata**, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, por força da LC est. (PE) 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o novo texto constitucional. É da jurisprudência do Supremo Tribunal — malgrado o

dissenso do Relator — que a antinomia entre norma ordinária anterior e a Constituição superveniente se resolve em mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta. O mesmo raciocínio é aplicado quando, por força de emenda à Constituição, a lei ordinária ou complementar anterior se torna incompatível com o texto constitucional modificado: precedentes” (ADI 3.569, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007, DJ de 11.05.2007).

■ 5.3. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA CONTIDA

As normas constitucionais de **eficácia contida** ou **prospectiva** têm **aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral**. Embora tenham condições de, quando da promulgação da nova Constituição, ou da entrada em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), produzir todos os seus efeitos, poderá haver a redução de sua abrangência.

Ao contrário do que ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada, como será visto no item seguinte, em relação às quais o legislador infraconstitucional amplia o âmbito de sua eficácia e aplicabilidade, no tocante às **normas constitucionais de eficácia contida** percebemos verdadeira limitação (restrição) à eficácia e à aplicabilidade.

A restrição de referidas normas constitucionais pode-se concretizar não só através de **lei infraconstitucional** mas, também, em outras situações, pela **incidência de normas da própria Constituição**, desde que ocorram certos pressupostos de fato, por exemplo, a decretação do estado de defesa ou de sítio, limitando diversos direitos (arts. 136, § 1.º, e 139 da CF/88).

Além da restrição da eficácia das referidas normas de eficácia contida tanto por lei como por outras normas constitucionais, conforme referido acima, a restrição poderá implementar-se, em outras situações, por **motivo de ordem pública, bons costumes e paz social**, conceitos vagos cuja redução se efetiva pela Administração Pública.

Enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia

plena.

Como **exemplo** citamos o **art. 5.º, XIII**, da CF/88, que assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, garante-se o direito do livre-exercício profissional, mas uma lei, por exemplo, o Estatuto da OAB, pode exigir que para nos tornarmos advogados sejamos aprovados em um **exame de ordem**. Sem essa aprovação, infelizmente, não poderemos exercer a profissão de advogado, sendo apenas bacharéis em direito. O que a **lei infraconstitucional** fez foi reduzir a amplitude do direito constitucionalmente assegurado.

A questão foi posta, e o STF entendeu que “o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de **proporcionalidade** e **não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício**. No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição — assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade — aduziu-se que a aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional” (**RE 603.583**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2011, Plenário, *Inf. 646/STF*).

Cabe alertar, contudo, conforme estabeleceu a Corte ao analisar referido dispositivo constitucional (art. 5.º, XIII), que “**nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício**. A regra é a liberdade. Apenas quando houver **potencial lesivo** na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. **A atividade de músico prescinde de controle**. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão” (**RE 414.426**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.08.2011, Plenário, *DJE* de 10.10.2011. No mesmo sentido: *RE 795.467-RG*, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.06.2014; *RE 635.023-ED*, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.12.2011, 2.ª T.; *RE 509.409*, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 31.08.2011 etc.).

Outros exemplos, ainda, podem ser constatados nos incisos VII,⁴ VIII, XV, XXIV, XXV,⁵ XXVII e XXXIII do art. 5.º; arts. 15, IV; 37, I; 170, parágrafo único etc.⁶

Importante⁶ notar que, como veremos, em algumas provas de concursos, o examinador utilizou a nomenclatura sugerida por Michel Temer para as normas constitucionais de eficácia contida, qual seja, **normas constitucionais de eficácia redutível** ou **restringível**, apesar de sua *aplicabilidade plena*. Segundo Temer, referidas normas “são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que podem ter reduzido seu alcance pela atividade do legislador infraconstitucional”.⁷

■ 5.4. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA LIMITADA

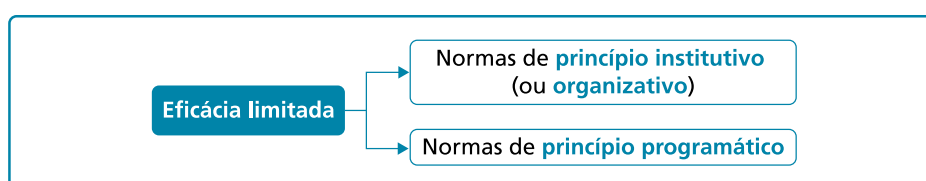
São aquelas normas que, de imediato, no momento que a Constituição é promulgada, ou entra em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de uma lei integrativa infraconstitucional, ou até mesmo de integração por meio de emenda constitucional, como se observou nos termos do art. 4.º da EC n. 47/2005.⁸ São, portanto, de **aplicabilidade indireta, mediata e reduzida**, ou, segundo alguns autores, **aplicabilidade diferida**.

Devemos salientar que, ao contrário da doutrina norte-americana, José Afonso da Silva, concordando com a opinião de Vezio Crisafulli, observa que as *normas constitucionais de eficácia limitada* produzem um mínimo efeito, ou, ao menos, o efeito de vincular o legislador infraconstitucional aos seus vetores.

Assim, José Afonso da Silva, em sede conclusiva, assevera que referidas normas têm, ao menos, **eficácia jurídica imediata, direta e vinculante**, já que: **a)** estabelecem um dever para o legislador ordinário; **b)** condicionam a legislação futura, com a consequência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; **c)** informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; **d)** constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; **e)** condicionam a atividade discricionária da Administração e do

Judiciário; **f)** criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de desvantagem.⁹ Todas elas — em momento seguinte concluiu o mestre¹⁰ — possuem eficácia ab-rogativa da legislação precedente incompatível (Geraldo Ataliba diria “paralisante da eficácia destas leis”, sem ab-rogá-las — nosso acréscimo) e criam situações subjetivas simples e de interesse legítimo, bem como direito subjetivo negativo. Todas, enfim, geram situações subjetivas de vínculo.

O mestre do Largo São Francisco divide-as em dois grandes grupos: **normas de princípio institutivo (ou organizativo)** e **normas de princípio programático**.



As *normas de eficácia limitada, declaratórias de princípios institutivos ou organizativos (ou orgânicos)* contêm **esquemas gerais (iniciais) de estruturação de instituições, órgãos ou entidades**. Podemos exemplificar com os arts. 18, § 2.º; 22, parágrafo único; 25, § 3.º; 33; 37, VII; 37, XI; 88; 90, § 2.º; 91, § 2.º; 102, § 1.º; 107, § 1.º; 109, VI; 109, § 3.º; 113; 121; 125, § 3.º; 128, § 5.º; 131; 146; 161, I; 224...¹¹

Já as *normas de eficácia limitada, declaratórias de princípios programáticos*, **veiculam programas a serem implementados pelo Estado**, visando à realização de fins sociais (arts. 6.º — direito à alimentação; 196 — direito à saúde; 205 — direito à educação; 215 — cultura; 218, *caput* — ciência, tecnologia e inovação (EC n. 85/2015); 227 — proteção da criança...).¹²

Alguns outros exemplos podem ser “colhidos” do vasto estudo desenvolvido por José Afonso da Silva. Vinculadas ao **princípio da legalidade**, o autor menciona algumas **normas programáticas: a)** art. 7.º, XI (participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, *conforme definido em lei*, observando que já existe ato normativo concretizando o direito); **b)** art. 7.º, XX (proteção do

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, *nos termos da lei*); **c)** art. 7.º, XXVII (proteção em face da automação, na *forma da lei*); **d)** art. 173, § 4.º (*a lei* reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros — *vide* CADE); **e)** art. 216, § 3.º; **f)** art. 218, § 4.º etc. [13](#)

Outros dois exemplos, de interesse prático, podem ser encontrados na jurisprudência do STF, já declarados como **normas de eficácia limitada**: **a)** juros legais de 12% ao ano; **b)** teto do funcionalismo público.

Em relação ao primeiro, o STF entendia, apesar da nossa crítica e de diversos outros autores, bem como de alguns tribunais (*vide Julgados do TARGS*, 81/314), que o **revogado art. 192, § 3.º**, que fixava as taxas dos **juros reais** não superiores a **12% a.a.**, era norma constitucional de eficácia limitada, dependente de lei complementar para sua aplicação prática. [14](#) **Convém lembrar a novidade trazida pela EC n. 40, de 29.05.2003** (PEC n. 53/99 da CD e n. 21/97 do SF), que, ao tratar do *Sistema Financeiro Nacional*, alterou a redação do inciso V do art. 163 e do *caput* do art. 52 do ADCT, revogando todos os incisos e parágrafos do art. 192, permitindo a sua regulamentação por **mais de uma lei complementar**. Em razão dessa nova sistemática, a já desprestigiada taxa de juros reais de 12% a.a. desconstitucionaliza-se, infelizmente, assim como as importantes regras que constavam do referido art. 192. No parecer do relator à PEC n. 53, a reforma buscou “... superar as dificuldades de regulamentação do art. 192 da Constituição Federal e viabilizar a aprovação de uma nova lei estruturadora do sistema financeiro nacional”, uma vez que o STF já havia resolvido que, na vigência da antiga regra, antes da EC n. 40/2003, portanto, o sistema financeiro deveria ser regulamentado por uma única lei complementar (cf. **Súmula Vinculante 7/2008**).

O segundo exemplo diz respeito ao **teto do funcionalismo público**. Como se sabe, a Reforma Administrativa (EC n. 19/98) fixou o teto correspondente ao subsídio mensal, em espécie, dos **Ministros do STF**, nos termos dos arts. 37, XI; 39, § 4.º, e 48, XV. Tratava-se, como definiu o STF, de **norma não autoaplicável, dependente de lei formal de iniciativa conjunta dos**

Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observadas as regras dos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III e 153, § 2.º, I. [15](#) Essas regras, contudo, não persistem, tendo em vista a promulgação da EC n. 41/2003.

A **Reforma da Previdência** (EC n. 41, de 19.12.2003) também estabeleceu como teto do funcionalismo público o subsídio pago ao Ministro do STF, a ser fixado por lei. Inovando, acaba com a denominada “iniciativa conjunta”, já que a fixação do teto dar-se-á por **lei de iniciativa exclusiva do Presidente do STF** (arts. 48, XV, e 96, II, “b” — sendo a CD a Casa iniciadora e o SF, a revisora — art. 64, *caput*) e não mais em conjunto pelos Presidentes dos “Poderes”.

Verificaremos que foram criados subtetos, nos termos do art. 37, XI, e §§ 11 e 12 (parágrafos introduzidos pela EC n. 47/2005), tema a ser estudado quando tratarmos da exclusão da regra da iniciativa conjunta (*item 9.13.3.5*).

A perspectiva de que referida regra (art. 37, XI) continue sendo classificada pelo STF como de **eficácia limitada** decorre não só do antigo posicionamento da Suprema Corte como, principalmente, da regra contida no art. 8.º da EC n. 41/2003, que tem a seguinte redação:

“**Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI**, da Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o **valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal**, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior remuneração mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal a que se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”.

Alexandre de Moraes considera o texto do inciso XI do art. 37 **autoaplicável**. [16](#) Em nossa interpretação, concordamos que o texto seja

autoaplicável. Essa autoaplicabilidade, contudo, não decorre da eficácia plena da norma (que, em nosso entender, é de **eficácia limitada**, já que prescreve a sua regulamentação por lei de iniciativa do Presidente do STF), mas do comando fixado no art. 8.º da EC n. 41/2003.

Tanto é verdade que o teto inicial, que era provisório, foi redefinido pela **Lei n. 11.143/2005**, tendo sido reajustado nos termos da **Lei n. 12.041/2009**, estando atualmente regulamentado pelas **Leis ns. 12.771/2012** e **13.091/2015** que estabeleceram o subsídio mensal de Ministro do STF, referido no inciso XV do art. 48 da CF/88, como sendo de: **a)** R\$ 28.059,29, a partir de 1.º.01.2013; **b)** R\$ 29.462,25, a partir de 1.º.01.2014; e **c)** R\$ 33.763,00, a partir de 1.º.01.2015 (as regras sobre o **teto do funcionalismo** foram modificadas pela **EC n. 47/2005** — tema a ser discutido nos *itens* 9.13.3.6 e 22.3.2 deste trabalho).

Então, uma coisa é a regra contida na Constituição, que depende de lei para sua regulamentação (eficácia limitada). Outra é o seu **valor provisório** (teto de retribuição) estabelecido no citado art. 8.º, da **EC n. 41/2003**. Esse dispositivo foi declarado pelo STF como de **“eficácia imediata”**, já que definiu um específico valor a ser observado até o formal estabelecimento do teto do funcionalismo por lei específica (**RE 609.381/GO**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 02.10.2014, *DJE* de 11.12.2014).

■ 5.5. A CLASSIFICAÇÃO DE **MARIA HELENA DINIZ**

Em primorosa monografia sobre o tema, Maria Helena Diniz, baseando-se em diversas classificações das **normas constitucionais quanto à sua eficácia**, apresentadas pela doutrina (Cooley, Rui Barbosa, Caetano Azzariti, Franchini, Vezio Crisafulli, José Afonso da Silva, Pinto Ferreira, Celso Bastos e Carlos A. Britto, Celso Antônio Bandeira de Mello), tendo por critério a questão da intangibilidade e da produção dos efeitos concretos, classifica as normas constitucionais (segundo a sua eficácia) em: **normas supereficazes** ou com **eficácia absoluta; normas de eficácia plena; normas com eficácia relativa**

restringível; normas com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa. [17](#)

■ **Normas supereficazes ou com eficácia absoluta:** são intangíveis, não podendo ser emendadas. Contêm uma força paralisante total de qualquer legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-las. Exemplos: textos constitucionais que amparam: *a*) a **federação** (arts. 1.º; 18; 34, VII, “c”; 46, § 1.º); *b*) o **voto direto, secreto, universal e periódico** (art. 14); *c*) a **separação de Poderes** (art. 2.º); *d*) os **direitos e garantias individuais** (art. 5.º, I a LXXVIII), enfim, as normas **intangíveis** por força dos arts. 60, § 4.º (as chamadas **cláusulas pétreas**), e 34, VII, “a” e “b”.

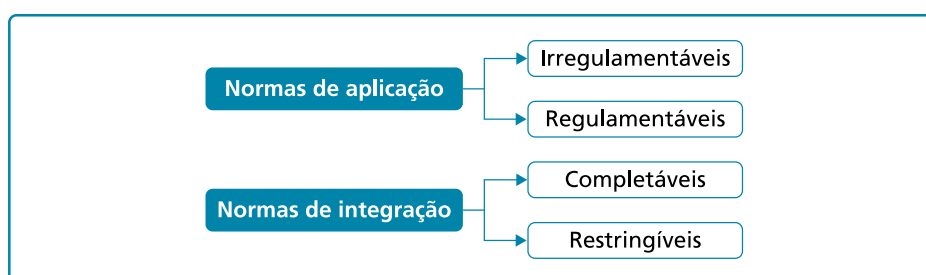
■ **Normas com eficácia plena:** contêm “... todos os elementos imprescindíveis para que haja a possibilidade da produção imediata dos efeitos previstos, já que, apesar de suscetíveis de emenda, não requerem normação subconstitucional subsequente. Podem ser imediatamente aplicadas. Consistem, por exemplo, nos preceitos que contenham proibições, confirmem isenções, prerrogativas e que não indiquem órgãos ou processos especiais para sua execução”. Exemplos: arts. 1.º, parágrafo único; 14, § 2.º; 17, § 4.º; 21; 22; 37, III; 44, parágrafo único; 69; 153; 155; 156 etc.

■ **Normas com eficácia relativa restringível:** correspondem às normas de eficácia contida na classificação exposta de José Afonso da Silva, com preferência para a nomenclatura proposta por Michel Temer (**eficácia redutível** ou **restringível**), sendo de aplicabilidade imediata ou plena. Enquanto não sobrevier a restrição, o direito nelas contemplado será pleno. Exemplos: arts. 5.º, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXIV, LX, LXI; 84, XXVI; 139; 170, parágrafo único; 184 etc.

■ **Normas com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa:** dependem de lei complementar ou ordinária para o exercício do direito ou benefício consagrado. “Sua possibilidade de produzir efeitos é mediata, pois, enquanto não for promulgada aquela lei complementar ou ordinária, não produzirão efeitos positivos, mas terão eficácia paralisante de efeitos de normas precedentes incompatíveis e

impeditivas de qualquer conduta contrária ao que estabelecerem.” Podem ser de **princípio institutivo** (“dependentes de lei para dar corpo a instituições, pessoas, órgãos, nelas previstos” — exemplos: arts. 17, IV; 25, § 3.º; 43, § 1.º etc.), ou **normas programáticas** (programas a serem desenvolvidos mediante lei infraconstitucional — exemplos: arts. 205; 211; 215; 218; 226, § 2.º etc.).

■ 5.6. A CLASSIFICAÇÃO DE *CELSO RIBEIRO BASTOS* E *CARLOS AYRES BRITTO*



Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto classificam as normas constitucionais em *normas de aplicação* (irregulamentáveis ou regulamentáveis) e *normas de integração* (completáveis ou restringíveis). [18](#)

As **normas de aplicação** já estão aptas a produzir todos os seus efeitos, dispensando regulamentação (ex.: art. 2.º da CF/88) ou permitindo-a, mas, nesta hipótese, sem qualquer restrição do conteúdo constitucional.

Já as **normas de integração**, como o nome sugere, são **integradas** pela legislação infraconstitucional. Entre elas e a sua aplicação real coloca-se outra norma integradora de sentido, fazendo surgir uma unidade de conteúdo entre as duas espécies normativas. Ora são **completáveis** (exigem uma legislação integrativa para a completa produção de seus efeitos — *sentido de complemento, colmatação ou preenchimento de um vazio regravatório preexistente*), ora **restringíveis** (estabelecem a possibilidade de o legislador infraconstitucional reduzir o comando constitucional — *acepção de encurtamento, redução ou contração de um campo regulatório de maior abrangência*).

■ 5.7. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA EXAURIDA E APLICABILIDADE ESGOTADA

Sugeridas por Uadi Lammêgo Bulos,¹⁹ as normas de eficácia exaurida, ou esvaída, “... são aquelas, como o próprio nome diz, que já extinguiram a produção de seus efeitos. Por isso, estão esgotadas, dissipadas, ou desvanecidas, condicionando, assim, sua aplicabilidade”. São próprias do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), notadamente aquelas normas que já cumpriram o papel, encargo ou tarefa para o qual foram propostas. Exemplos: arts. 1.º, 2.º, 3.º, 14, 20, 25, 48 e vários outros do ADCT.

■ 5.8. NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E O GRADUALISMO EFICACIAL DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o art. 5.º, § 1.º, da CF/88, têm **aplicação imediata**.

O termo “aplicação” **não** se confunde com “aplicabilidade”, na teoria de José Afonso da Silva, que entende, como visto, terem as normas de eficácia **plena e contida** “aplicabilidade” **direta e imediata**, e as de eficácia **limitada**, aplicabilidade **mediata** ou **indireta**.

Ensina José Afonso da Silva que ter **aplicação imediata** significa que as normas constitucionais são “dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. A regra é que as normas definidoras de *direitos e garantias individuais* (direitos de 1.ª dimensão, acrescente-se) sejam de *aplicabilidade imediata*. Mas aquelas definidoras de *direitos sociais, culturais e econômicos* (direitos de 2.ª dimensão, acrescente-se) nem sempre o são, porque não raro dependem de providências ulteriores que lhes completem a eficácia e possibilitem sua aplicação”.²⁰

Dessa maneira, “por regra, as normas que consubstanciam os *direitos fundamentais democráticos e individuais* são de *aplicabilidade imediata*,

enquanto as que definem os *direitos sociais* tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma lei integradora, são de *eficácia limitada e aplicabilidade indireta*”.²¹

Como exemplo de norma definidora de direito e garantia fundamental que depende de lei, podemos citar o **direito de greve** dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, ou o da **aposentadoria especial**, garantido nos termos do art. 40, § 4.º.

Então, qual seria o sentido dessa regra inscrita no art. 5.º, § 1.º?

José Afonso da Silva explica: “*em primeiro lugar*, significa que elas são aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. *Em segundo lugar*, significa que o Poder Judiciário, sendo invocado a propósito de uma **situação concreta** nelas garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes”.²²

Assim, diante de omissão de **medida** para tornar efetiva norma constitucional, a CF/88 trouxe duas importantes novidades: a **ação direta de inconstitucionalidade por omissão — ADO** (agora regulamentada na Lei n. 12.063, de 27.10.2009, e por nós comentada no *item 6.7.4*) e o **mandado de injunção** (MI, art. 5.º, LXXI, estudado no *item 14.11.5*).

Em relação a esses dois remédios para combater a “síndrome de inefetividade” das normas constitucionais de eficácia limitada, o STF tende a consolidar o entendimento de que, em se tratando de “Poder”, a ADO seria o instrumento para fazer um **apelo** ao legislador, constituindo-o em mora, enquanto o MI, por seu turno, seria o importante instrumento de **concretização** dos direitos fundamentais, como vem sendo percebido na jurisprudência do STF (cf. *item 14.11.5.4*) e, assim, dando um exato sentido ao art. 5.º, § 1.º, que fala em **aplicação imediata**. Vejamos:

“EMENTA: **Mandado de injunção**. Natureza. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5.º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à

cidadania. Há **ação mandamental** e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. Mandado de injunção. Decisão. Balizas. Tratando-se de processo subjetivo, a **decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada**. Aposentadoria. Trabalho em condições especiais. Prejuízo à saúde do servidor. Inexistência de lei complementar. Artigo 40, § 4.º, da Constituição Federal. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, **impõe-se** a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral — artigo 57, § 1.º, da Lei n. 8.213/91” (MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.º.07.2008, Plenário, *DJE* de 26.09.2008).²³

Ainda, conforme bem definiu a Min. Cármen Lúcia, no julgamento de vários Mandados de Injunção (MI 828/DF, MI 841/DF, MI 850/DF, MI 857/DF, MI 879/DF, MI 905/DF, MI 927/DF, MI 938/DF, MI 962/DF, MI 998/DF), “o mandado de injunção é ação constitucional de **natureza mandamental**, destinada a **integrar a regra constitucional ressentida, em sua eficácia**, pela ausência de norma que assegure a ela o vigor pleno”.

Qualquer outro entendimento geraria o mais nefasto sentimento de frustração e desprestígio aos direitos fundamentais, reduzindo a importante conquista do MI a um nada.

Assim, Maria Helena Diniz refere-se a um **gradualismo eficaz das normas constitucionais**. “Há um escalonamento na intangibilidade e nos efeitos dos preceitos constitucionais... Todas têm juridicidade, mas seria uma utopia considerar que têm a mesma eficácia, pois o seu grau eficaz é variável. Logo, **não há norma constitucional destituída de eficácia**. Todas as disposições constitucionais têm a possibilidade de produzir, a sua maneira, concretamente, os efeitos jurídicos por elas visados.”²⁴

■ 5.9. EFICÁCIA E APLICABILIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO STF

Dado o objetivo do presente estudo, acreditamos interessante **esquematizar** importantes julgados do STF definindo a eficácia e aplicabilidade de algumas

normas da Constituição — o que, certamente, facilitará para as provas e concursos —, bem como para o nosso ilustre e nobre professor trabalhar os precedentes em sala de aula com os alunos (*cases*):

PRECEDENTE	MATÉRIA	EFICÁCIA E APLICABILIDADE (STF)
■ ADPF 130 — Rel. Min. Carlos Britto, j. 30.04.2009, Plenário, <i>DJE</i> de 06.11.2009	■ art. 5.º, V — direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ Mesmo diante do reconhecimento da não recepção da Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67), o STF entendeu que o artigo 5.º, V, “se qualifica como regra de suficiente densidade normativa, podendo ser aplicada imediatamente, sem necessidade de regulamentação legal”
■ Ext. 541 — Rel. p/ o ac. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07.11.91, Plenário, <i>DJ</i> de 18.12.92) ■ Ext. 934-	■ art. 5.º, LI (parte final) — extradição do brasileiro naturalizado no caso de comprovado	■ Eficácia limitada e aplicabilidade mediata e reduzida ■ “Ao princípio geral de inextraditabilidade do brasileiro, incluído o naturalizado, a Constituição admitiu, no art. 5.º, LI, duas exceções: a primeira, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, se a naturalização é posterior ao crime comum pelo qual procurado; a segunda, no caso de naturalização anterior ao fato, se se cuida de tráfico de entorpecentes: aí, porém, admitida, não como a de qualquer estrangeiro, mas, sim, ‘na forma da lei’, e por ‘comprovado envolvimento’ no crime: a essas exigências de ■ caráter excepcional não basta a concorrência dos requisitos formais de toda extradição, quais

■ Ext. 934-QO, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.09.2004, Plenário, <i>DJ</i> de 12.11.2004)	em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei	sejam, a dúplice incriminação do fato imputado e o juízo estrangeiro sobre a seriedade da suspeita. (...); para a extradição do brasileiro naturalizado antes do fato, porém, que só a autoriza no caso de seu ‘comprovado envolvimento’ no tráfico de drogas, a Constituição impõe à lei ordinária a criação de um procedimento específico, que comporte a cognição mais ampla da acusação na medida necessária à aferição da concorrência do pressuposto de mérito, a que excepcionalmente subordinou a procedência do pedido extraditório: por isso, a norma final do art. 5.º, LI, CF, não é regra de eficácia plena, nem de aplicabilidade imediata”
■ RE 161.547, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.03.98, 1.ª Turma, <i>DJ</i> de 08.05.98	■ art. 8.º, IV — contribuição confederativa instituída pela assembleia geral	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ “EMENTA: Sindicato: contribuição confederativa instituída pela assembleia geral: eficácia plena e aplicabilidade imediata da regra constitucional que a previu (CF, art. 8.º, IV). Coerente com a sua jurisprudência no sentido do caráter não tributário da contribuição confederativa, o STF tem afirmado a eficácia plena e imediata da norma constitucional que a previu (CF, art. 8.º, IV)...”
■ ADI 3.768, Rel. Min. Cármen Lúcia,	■ art. 230, § 2.º — estabelece a gratuidade dos	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ A questão surgiu a partir da regulamentação da matéria pelo art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (<i>Estatuto do Idoso</i>) ■ Segundo o STF, a norma infraconstitucional “...

j. 19.09.2007, <i>DJ</i> de 26.10.2007	coletivos urbanos aos maiores de 65 anos	Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”
■ RE 285.706, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 26.03.2002, <i>DJ</i> de 26.04.2002	■ art. 17 do ADCT — vencimentos e proventos — redução imediata aos limites constitucionais	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ “Vencimentos e proventos: redução imediata aos limites constitucionais (ADCT, art. 17): eficácia plena e aplicabilidade imediata: vinculação direta do órgão administrador competente, desnecessária, portanto, a interposição de lei ordinária ou ato normativo equivalente: interpretação conjugada do art. 17 do ADCT e do art. 37, XI, da Constituição”
■ RE 417.871-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 15.02.2005, <i>DJ</i> de 11.03.2005. No mesmo sentido: RE 421.197-AgR,	■ art. 53, IV, do ADCT — ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n. 5.315/67,	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata

421.197-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 15.08.2006, <i>DJ</i> de 08.09.2006	será assegurado, dentre outros, o direito à assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes	
■ AI 396.695-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 02.12.2003, <i>DJ</i> de 06.02.2004	■ art. 201, § 5.º — veda a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência ■ art. 201, § 6.º — a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ “As normas inscritas nos § 5.º e § 6.º do art. 201 da Constituição Federal são de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O disposto no § 5.º do art. 195 da Lei Maior e nos artigos 58 e 59, ADCT, não lhes retira a autoaplicabilidade”

	valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano	
■ ADI 3.569, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007, <i>DJ</i> de 11.05.2007	■ art. 134, § 2.º — assegura às defensorias públicas estaduais a autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária (EC n. 45/2004)	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ Cf. <i>item 5.2</i>, anterior, no qual transcrevemos a importante ementa
■ MI 626, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.03.2001, Plenário, <i>DJ</i> de 18.06.2001	■ Art. 8.º, ADCT, com a exceção do seu § 3.º — anistia	■ Eficácia plena e aplicabilidade imediata ■ A anistia de que cuida o art. 8.º do ADCT beneficiou civis e militares, estando, entre os primeiros, servidores, empregados e profissionais liberais, enfim todo e qualquer cidadão qualificado como trabalhador ■ Segundo o STF, apenas o art. 8.º, § 3.º, do ADCT, é que depende de lei, sendo, no caso específico, de eficácia limitada
	■ art. 5.º, XIII	

■ MI 6.113-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.05.2014, Plenário, <i>DJE</i> de 13.06.2014	— é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer	■ Eficácia contida e aplicação imediata ■ “O art. 5.º, XIII, da CR é norma de aplicação imediata e eficácia contida que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício”
■ RE 544.655-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.09.2008, <i>DJE</i> de 10.10.2008	■ art. 37, I — os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei	■ Eficácia limitada (em relação aos estrangeiros — <i>na forma da lei</i>) ■ “Estrangeiro. Acesso ao serviço público. Artigo 37, I, da CF/88. O STF fixou entendimento no sentido de que o artigo 37, I, da Constituição do Brasil [redação após a EC 19/98], consubstancia, relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos, sendo assim, não autoaplicável” ■ Eficácia contida (em relação aos brasileiros) ■ Brasileiros: a lei prevista no art. 37, I, não cria o direito, mas o restringe (o reduz) ao estabelecer requisitos para seu exercício
■ MI 670, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, e MI 712, Rel.		■ Eficácia limitada

j. 25.10.2007, <i>DJE</i> de 31.10.2008 ■ MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007, <i>DJE</i> de 31.10.2008	■ art. 37, VII — direito de greve dos servidores públicos	■ Cabe lembrar que o STF, adotando a posição concretista geral, julgou procedentes os referidos MIs, determinando, até que o Congresso Nacional legisle, a aplicação da lei da iniciativa privada para todo o funcionalismo público (cf. <i>item 14.11.5.4</i> e <i>item 13.7.10</i> sobre a não aplicação em serviços essenciais, como é o caso dos policiais civis)
■ MI 1.616, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.11.2009, <i>DJE</i> de 11.11.2009	■ art. 40, § 4.º — aposentadoria especial para os servidores públicos	■ Eficácia limitada ■ O STF vem determinando a aplicação do art. 57, § 1.º, da Lei n. 8.213/91, até que a matéria seja regulamentada pelo Congresso Nacional (cf. <i>item 14.11.5.4</i>, bem como a SV 33/2014)
■ ADI 2.240, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.05.2007, Plenário, <i>DJ</i> de 03.08.2007 ■ ADO 3.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.05.2007, <i>DJE</i> de 06.09.2007	■ art. 18, § 4.º — procedimento para a criação de Municípios	■ Eficácia limitada ■ Conforme estudamos no <i>item 7.6.1</i>, no julgamento da ADI 2.240, o STF reconheceu a nulidade das leis estaduais que criaram Municípios sem a definição de procedimento por lei complementar federal, declarando a modulação dos efeitos da decisão por 24 meses ■ Também, no julgamento da ADO 3.682, o STF fez um apelo ao Legislativo para suprir a omissão, dentro de 18 meses ■ Contudo, o Congresso Nacional não regulamentou a matéria. Para piorar, nos termos da, por nós criticada, EC n. 57/2008, convalidou os

06.09.2007		atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios cuja lei tivesse sido publicada até 31.12.2006
■ ADI 1.330-MC, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 10.08.1995, Plenário, <i>DJ</i> de 20.09.2002	■ art. 187 — planejamento e execução da política agrícola na forma da lei	■ Eficácia limitada ■ De acordo com o STF, o art. 187 é norma programática, na medida em que prevê especificações em lei ordinária. Isso porque, de acordo com a referida regra, a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta diversos preceitos indicados no referido dispositivo
■ ADPF 144, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.08.2008, Plenário, <i>DJE</i> de 26.02.2010	■ art. 14, § 9.º — outras hipóteses de inelegibilidade além das expressamente previstas na CF/88	■ Eficácia limitada ■ Conforme estudamos no <i>item 17.4.2</i> (candidatos “ficha suja”), o STF entendeu que a regra contida no art. 14, § 9.º, não é autoaplicável, dependendo, então, para serem criadas outras hipóteses de inelegibilidade, além das expressamente previstas na Constituição, de lei complementar. A regulamentação se deu nos termos da LC n. 64/90 e, mais recentemente, pela LC n. 135/2010
		■ Eficácia limitada — interessante proposta de concretização

■ **RE 271.286-AgR**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000, 2.^a Turma, *DJ* de 24.11.2000. No mesmo sentido: **STA 175-AgR**, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. 17.03.2010, Plenário, *DJE* de 30.04.2010

■ *Vide:* **AI 734.487-AgR**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03.08.2010, 2.^a Turma, *DJE* de 20.08.2010

■ **art. 196** — direito à saúde

■ “O **direito público subjetivo à saúde** representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o **Poder Público**, a quem incumbe formular — e implementar — políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O **direito à saúde** — além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas — representa consequência constitucional indissociável do **direito à vida**. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. **A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente**. O **caráter programático** da regra inscrita no art. 196 da Carta Política — que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — **não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente**, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o

		ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5.º, <i>caput</i>, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”
■ MI 369, Rel. p/ o ac. Min. Francisco Rezek, j. 19.08.1992, Plenário, <i>DJ</i> de 26.02.1993 ■ MI 1.090, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.02.2013, Plenário, <i>DJE</i> de 23.04.2013	■ art. 7.º, XXI — aviso prévio proporcional ao tempo de serviço	■ Eficácia limitada ■ Cf. <i>item 3.7.2.1.</i>
■ RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, j.		■ Eficácia limitada ■ Conforme voto do Min. Moreira Alves (RE

16.05.97. No mesmo sentido: RE 637.282, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 23.08.2012, <i>DJE</i> de 31.08.2012	remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei	art. 7.º, XXIII, da Constituição Federal teve aplicação imediata por ter sido recebido pela atual Carta Magna o disposto no art. 193 da CLT e os atos que o regulamentam; o mesmo não ocorre, porém, com os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que dependem , para a percepção dessas vantagens, da respectiva legislação referente a seu regime jurídico ” (nesse ponto a eficácia limitada, acrescente-se)
--	--	--

■ 5.10. QUESTÕES

1. (OAB/113.º/SP) Recentemente, o STF entendeu que, até que haja lei definindo o subsídio mensal a ser pago a ministro do STF, não prevaleceria o teto único de remuneração para os três Poderes da República, estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Esta decisão entendeu, portanto, que a norma constitucional que estabeleceu o teto único de remuneração seria norma:

- a) de eficácia limitada e aplicação diferida;
- b) de eficácia plena e aplicabilidade imediata;
- c) de eficácia contida e aplicabilidade imediata;
- d) autoaplicável.

2. (OAB/117.º/SP) São normas constitucionais de eficácia contida aquelas:

- a) em que o legislador constituinte regulou suficiente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte do legislador infraconstitucional;
- b) que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os seus efeitos;
- c) por meio das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuição de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estructure, em definitivo, mediante lei;
- d) em que o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados

atribuição de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture, em definitivo, mediante lei;

- d) em que o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limita-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos e judiciais).

3. (OAB/108.º) A norma constitucional que garante a todos “o livre-exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, é norma:

- a) de aplicabilidade plena e de eficácia redutível;
- b) de eficácia limitada;
- c) de eficácia plena;
- d) programática.

4. (OAB/113.º) A norma que dispõe que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” é norma constitucional:

- a) de aplicabilidade plena, mas com eficácia redutível;
- b) programática;
- c) de eficácia limitada;
- d) de aplicabilidade e eficácia plenas.

5. (OAB/112.º) Quanto à aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, o art. 5.º, XV, da Constituição da República, que prevê ser “livre a locomoção no território nacional em tempo de paz” com a possibilidade de “qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”, pode ser considerado norma de eficácia:

- a) plena, não comportando nenhuma espécie de restrição;
- b) contida, sendo de aplicação imediata, porém com possibilidade de restrição;
- c) limitada, pois sua aplicação depende de regulamentação por lei;
- d) limitada, por não ser autoaplicável.

6. (Magistratura/171.º) O art. 2.º da CF: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”, é norma de:

- a) eficácia plena;

- b) eficácia limitada;
- c) eficácia contida;
- d) eficácia semiplena.

7. (OAB/110.º) Com relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, o art. 7.º, XXVII, da Constituição Federal, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais “proteção em face da automação, na forma da lei”, pode ser considerado norma de eficácia:

- a) limitada, porque a aplicação do dispositivo está restrita aos trabalhadores urbanos e rurais;
- b) semilimitada, porque, embora totalmente aplicável, seu conteúdo pode ser restringido por lei;
- c) contida, porque, embora totalmente aplicável, seu conteúdo pode ser ampliado por lei;
- d) limitada, porque a aplicação do dispositivo na sua totalidade depende de norma regulamentadora.

8. (Magistratura MG/2003-2004) As normas constitucionais insuscetíveis de emenda, com força paralisante de toda a legislação que vier a contrariá-las são denominadas normas constitucionais:

- a) com eficácia plena;
- b) de eficácia plena e aplicabilidade imediata;
- c) com eficácia absoluta;
- d) de eficácia limitada;
- e) substantivas.

9. (Magistratura MG/2003-2004) As normas constitucionais denominadas de exauridas constam:

- a) do preâmbulo constitucional;
- b) do ato das disposições constitucionais transitórias;
- c) do processo legislativo;
- d) da ordem social;
- e) da ordem econômica e financeira.

10. (Auditor Fiscal Estadual — Ceará/2007 — ESAF) Sobre a aplicabilidade das

única opção correta.

- a) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e eficácia plena.
- b) As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que apresentam aplicabilidade reduzida, haja vista necessitarem de norma ulterior para que sejam aplicadas.
- c) As normas constitucionais de eficácia limitada estreitam-se com o princípio da reserva legal, haja vista regularem interesses relativos a determinada matéria, possibilitando a restrição por parte do legislador derivado.
- d) O condicionamento da aplicação de direitos e garantias fundamentais à preexistência de lei não retira o poder normativo do dispositivo constitucional, haja vista impor ao legislador e ao aplicador da norma limites de atuação.
- e) Caberá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Logo, poderá ser impetrado o remédio constitucional para sanar a omissão de norma de eficácia contida.

11. (PFN/2006 — ESAF) Uma norma constitucional programática pode servir de paradigma para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade.

12. (Fiscal Receita Est./ACRE/2006 — CESPE/UnB) A erradicação da pobreza e da marginalização são tidas como normas de eficácia plena por grande parte da doutrina e da jurisprudência.

13. (Analista Judiciário — Área Administrativa/TRE-SP/2006 — FCC) Tendo em vista a aplicabilidade das normas constitucionais, considere o que segue:

- I. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- II. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Tais preceitos são considerados, respectivamente, normas constitucionais de:

- a) eficácia redutível ou restringível; e de princípio programático.
- b) eficácia limitada; e de princípio programático.
- c) princípio institutivo; e de eficácia plena.
- d) eficácia redutível ou restringível; e de eficácia absoluta.
- e) princípio contido; e de princípio institutivo.

- I. Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas destituídas de qualquer eficácia jurídica e social enquanto não sobrevier legislação integrativa infraconstitucional que lhes dê aplicabilidade.
- II. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que têm aplicabilidade plena, produzindo efeitos imediatos desde a entrada em vigor da Constituição, podendo, contudo, ter o seu alcance reduzido por atuação do legislador infraconstitucional.
- III. Poderá ser impetrado mandado de injunção para sanar omissão de norma constitucional de eficácia limitada.
- IV. Normas constitucionais de princípio institutivo ou organizativo são aquelas através das quais o constituinte traça princípios para serem cumpridos pelos órgãos legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos, como programas das respectivas atividades, objetivando a realização dos fins sociais do Estado.

Considerando as proposições acima como Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a alternativa que exprime a sequência CORRETA:

- a) F, V, V, F.
- b) V, F, F, V.
- c) F, V, V, V.
- d) V, F, V, V.
- e) F, F, F, V.

15. (Analista Judiciário/MT — Vunesp/TJMT/2008) Quando a falta de norma regulamentadora impedir o exercício dos direitos e liberdades constitucionais do cidadão, este poderá ajuizar:

- a) o mandado de segurança.
- b) o mandado de injunção.
- c) o *habeas data*.
- d) a ação direta de inconstitucionalidade.
- e) a ação popular.

16. (OAB/MG — CEO/2009) Assinale certo ou errado (adaptada):

Os direitos e garantias fundamentais sempre estão previstos em normas constitucionais de eficácia plena.

17. (AFRFB/2005 — ESAF) Sobre conceito de Constituição e suas classificações e

eficácia plena.

17. (AFRFB/2005 — ESAF) Sobre conceito de Constituição e suas classificações e sobre a aplicabilidade e interpretação de normas constitucionais, marque a única opção correta (adaptada):

O art. 5.º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988, que estabelece “Art. 5.º [...] inciso XXII — é garantido o direito de propriedade”, é uma norma constitucional de eficácia contida ou restringível.

18. (AGU — CESPE/UnB/2010) A respeito das normas constitucionais programáticas, julgue o seguinte item:

De acordo com entendimento do STF, configura exemplo de norma constitucional programática o preceito constitucional segundo o qual a política agrícola deve ser planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo tanto produtores e trabalhadores rurais, como setores de comercialização, de armazenamento e de transportes.

19. (Procurador do MP junto ao TCE/RO — FCC/2010) Em fevereiro de 2010, o artigo 6.º da Constituição Federal foi alterado para que, ao rol dos direitos fundamentais que prevê, fosse acrescentado o direito à alimentação. A eficácia desse direito é classificada como:

- a) plena.
- b) contida de princípio programático.
- c) limitada de princípio institutivo.
- d) contida de princípio institutivo.
- e) limitada de princípio programático.

20. (Técnico Administrativo MPU/CESPE/UnB/2010) A respeito dos princípios fundamentais, das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir:

As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo; por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral.

21. (Auditor Fiscal da Receita Estadual/SC/2010) Com respeito ao modelo constitucional brasileiro, é correto afirmar:

- a) As normas programáticas, por serem princípios, também possuem eficácia interpretativa.
- b) O legislador não pode ser destinatário imediato de normas programáticas.
- c) As normas programáticas não podem tratar de matéria atinente a políticas públicas.
- d) Os direitos fundamentais de segunda dimensão não podem ser objeto de normas programáticas.
- e) A eficácia ab-rogativa das normas programáticas não impede que legislação ulterior restrinja algum direito subjetivo por elas consagrado.

22. (Defensor Público/ES — CESPE/UnB/2009) Normas constitucionais supereficazes ou com eficácia absoluta são aquelas que contêm todos os elementos imprescindíveis para a produção imediata dos efeitos previstos; elas não requerem normatização subconstitucional subsequente, embora sejam suscetíveis a emendas.

23. (Analista Judiciário — Execução de Mandados — STM — CESPE/UnB/2011) Consideram-se normas de eficácia absoluta os preceitos constitucionais intangíveis, que são inalteráveis mesmo por meio de propostas de emendas constitucionais.

24. (Procurador TCE-SP — FCC/2011) Considera-se de eficácia limitada a norma constitucional segundo a qual:

- a) os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
- b) não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, assim definido em lei.
- c) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- d) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- e) os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

25. (Procurador Especial de Contas — TCM-BA — FCC/2011) Considera-se de eficácia plena e aplicabilidade imediata a norma constitucional que assegura:

- a) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias.
- b) direito de greve aos ocupantes de cargos, empregos e funções da Administração direta e indireta.
- c) gratuidade aos atos necessários ao exercício da cidadania.
- d) promoção da defesa do consumidor pelo Estado.
- e) direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

26. (II Defensor Público/AM — Instituto Cidades/2011) No art. 196 da Constituição Federal está estabelecido que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Assinale “certo” ou “errado” (adaptado pelo autor, tendo em vista que a prova é de múltipla escolha e com 5 alternativas):

- a) programática, mas, não obstante essa característica, se algum paciente carente com patologia crônica com indiscutível risco de morte necessitar de remédio de alto custo não fornecido pelo SUS — Sistema Único de Saúde —, será possível mover ação judicial para sua obtenção e, se houver recurso, em última instância a pretensão será acolhida.

27. (Analista Judiciário — TRT1 — Psicologia — FCC/2011) Os remédios constitucionais são tidos por normas constitucionais de eficácia:

- a) plena;
- b) limitada;
- c) contida;
- d) mediata;
- e) indireta.

28. (Analista Judiciário — TRT4 — Área Judiciária — FCC/2011) Analise:

- I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
- II. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Em conformidade com o aspecto doutrinário, as referidas disposições caracterizam-se,

- b) princípio programático e de eficácia contida;
- c) eficácia restringível e de eficácia absoluta;
- d) princípio programático e de eficácia plena;
- e) eficácia relativa e de princípio programático.

29. (Professor Direito — CESPE/UnB — IFB/2011) Entre as normas constitucionais de eficácia exaurida, incluem-se dispositivos constantes das disposições constitucionais transitórias.

30. (TST — Analista Judiciário — Área Administrativa — FCC/2012) Considere a seguinte norma constitucional prevista no artigo 5.º, XV, da Constituição Federal de 1988: É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Trata-se de norma de eficácia:

- a) plena.
- b) limitada.
- c) contida.
- d) exaurida.
- e) absoluta.

31. (Analista Judiciário — Área Judiciária — TRE-RJ — CESPE/UnB/2012) Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais (...) na Constituição Federal de 1988:

As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade mediata, já que, para que se efetivem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador.

32. (Magistratura — TJ-PR — UFPR/2012) Em relação à aplicabilidade e à eficácia das normas constitucionais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A norma do art. 5.º, III da Constituição Federal, segundo a qual “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, é dotada de eficácia plena.
- b) De acordo com o STF, o art. 192, § 3.º da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano e estabelecia que “a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”, veiculava norma

todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”, veiculava norma constitucional de eficácia contida.

- c) O art. 7.º, XI da Constituição Federal, que institui o direito do trabalhador à “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”, veicula norma de eficácia limitada.
- d) O art. 5.º, XIII da Constituição Federal, que assegura a liberdade de “exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, constitui norma de eficácia contida, passível de ser restringida pelo legislador, como no caso da restrição imposta pela exigência de aprovação do exame da OAB para o exercício da profissão de advogado.

33. (Analista Processual — TJ/RR — CESPE/UnB/2012) A respeito de constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue.

A norma constitucional que preveja a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa configura exemplo de norma de eficácia limitada.

34. (Analista Ministerial — Área Administrativa — MP/PI — Cargo 1 — CESPE/UnB/2012) Julgue o seguinte item, relativo à aplicabilidade das normas constitucionais:

A gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos é uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

35. (Analista Judiciário — Área Judiciária — TRT10 — CESPE/UnB/2013) No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item seguinte.

As normas constitucionais de eficácia limitada, embora, para produzirem todos os seus efeitos, demandem lei integrativa, têm o poder de vincular o legislador ordinário, podendo servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade.

36. (Agente Administrativo — TCE-RO — CESPE/UnB/2013) Ao determinar que os cargos, os empregos e as funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, a CF estabelece norma de eficácia limitada.

37. (Contador — TCE/RO — CESPE/UnB/2013) A respeito da eficácia das normas constitucionais, julgue o item que se segue.

constitucionais, julgue o item que se segue.

Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais.

38. (Analista Administrativo — ANTT — Direito — CESPE/UnB/2013) Acerca de constituição e de normas constitucionais, julgue o item a seguir:

As normas constitucionais de eficácia absoluta, mesmo sendo intangíveis, submetem-se ao processo de emenda constitucional.

39. (Agente Penitenciário — DEPEN — CESPE/UnB/2013) No que concerne às noções de direito constitucional, julgue o item que se segue:

Segundo a Constituição Federal de 1988, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada.

40. (Analista Judiciário — Oficial de Justiça Avaliador — TRT 16.^a R. — FCC/2014) Analise a seguinte norma constitucional inerente aos direitos sociais: Art. 8.º: É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) IV — a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.

Trata-se de norma de eficácia

- a) exaurida.
- b) limitada.
- c) plena.
- d) contida.
- e) programática.

41. (Analista Legislativo/CD — Consultor Legislativo — Área VIII — CESPE/UnB/2014) Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e às garantias fundamentais:

Se o poder público tiver a intenção de condicionar o exercício de determinada profissão a certas exigências, e se tais exigências forem estabelecidas mediante lei formal, elas

serão constitucionais, pois o Estado tem discricionariedade para eleger as restrições que entenda cabíveis para todos os ofícios ou profissões, desde que o faça por lei federal.

■ GABARITO ■

1. “a”. Lembrar a nova redação conferida ao inciso XI do art. 37 pela EC n. 41/2003 (Reforma da Previdência), que, em nosso entender, no tocante à eficácia e aplicabilidade, continua mantendo a linha de entendimento do STF, qual seja, ser a norma de eficácia limitada, dependendo, agora, de fixação por lei federal ordinária de iniciativa do Presidente do STF (art. 96, II, “b”), aprovada pelo Congresso Nacional (art. 48, XV). Essa perspectiva é reforçada nos termos do art. 8.º da EC n. 41/2003. A matéria foi regulamentada pela Lei n. 11.143/2005 e as regras sobre o teto “revisitadas” pela EC n. 47/2005 (arts. 37, §§ 11 e 12, e 4.º da EC n. 47/2005).
2. “a”.
3. “a”. A OAB/SP utilizou a nomenclatura sugerida por Michel Temer. Observamos que os concursos, ao revés, vêm preferindo a nomenclatura sugerida pelo Professor José Afonso da Silva e, no caso, melhor seria dizer norma constitucional de eficácia contida. (Este teste poderia ser respondido por exclusão, para quem não conhece a proposta formulada pelo Professor Temer!). Conforme visto, o STF, no julgamento do RE 603.583, com repercussão geral, considerou constitucional a obrigatoriedade do Exame da OAB para que bacharéis em Direito possam exercer a advocacia.
4. “a”. Mais uma vez, conforme visto acima, a OAB/SP utilizou a nomenclatura sugerida por Michel Temer. Trata-se, na classificação de José Afonso da Silva, de normas de eficácia contida.
5. “b”.
6. “a”.
7. “d”.
8. “c”. Nitidamente o ilustre examinador de Minas Gerais utilizou a classificação de Maria Helena Diniz, exposta na parte teórica.

10. “d”. A letra “a” está errada, pois nem todo direito e garantia terá eficácia plena. Alguns direitos foram fixados como normas programáticas, dependendo de lei para a implementação. Segundo a doutrina de José Afonso da Silva, que fala em aplicabilidade imediata para as normas de eficácia plena e contida, a regra do art. 5.º, § 1.º (aplicação imediata para as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais), não encontra total consonância, pois vão existir direitos que dependerão de lei para a implementação. Percebam que parece haver diferença entre aplicabilidade e aplicação. A letra “b” está errada, pois as normas de eficácia contida têm eficácia plena até que venha eventual lei restringindo a sua amplitude. A letra “c” inicia de modo correto, mas conclui dando o conceito de norma de eficácia contida (a possibilidade de restrição pelo legislador — tanto é que são chamadas, as normas de eficácia contida, de normas de eficácia restringível ou redutível). A letra “d” confirma a ideia de um mínimo de eficácia jurídica como característica das normas de eficácia limitada. A letra “e” está errada, pois o MI está direcionado às omissões legislativas, logo, tem por objeto norma de eficácia limitada.
11. “certo”.
12. “errado”. Pois a previsão desse objetivo fundamental (art. 3.º, III) é norma programática.
13. “d”. A <i>Fundação Carlos Chagas</i> utilizou a doutrina da Profa. Maria Helena Diniz (<i>vide</i> parte teórica).
14. “a”.
15. “b”. Lembramos que o tema sobre os remédios constitucionais será retomado no <i>item 14.11</i> deste trabalho.
16. “errado”. Cf. <i>item 5.8</i> da parte teórica.
17. “certo”. Cf. <i>item 5.3</i> da parte teórica, no qual destacamos: “o inciso XXII do art. 5.º garante o direito de propriedade, mas os incisos XXIV e XXV oferecem os elementos de suas limitações, permitindo sua desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, bem como seu uso pela autoridade competente no caso de perigo público iminente”.
18. “certo”.
19. “e”.
20. “errado”. As normas de eficácia plena, na conceituação de José Afonso da Silva, têm

20. “errado”. As normas de eficácia plena, na conceituação de José Afonso da Silva, têm aplicabilidade direta, imediata e integral.
21. “a”.
22. “errado”. Confira classificação de Maria Helena Diniz no <i>item 5.5</i>.
23. “certo”. Novamente, foi considerada a nomenclatura de Maria Helena Diniz.
24. “a”. Art. 7.º, XI, exemplo esse expressamente citado por José Afonso da Silva, conforme visto na parte teórica. A <i>letra “b”</i> traz exemplo de norma de eficácia plena, prevista no art. 5.º, LII. Apenas fazemos uma crítica no sentido de que o texto da Constituição não contém a expressão “<i>assim definido em lei</i>”, o que poderia gerar dúvida no candidato. A <i>letra “c”</i> estabelece norma prevista no art. 5.º, II, de eficácia plena. A <i>letra “d”</i> traz o típico exemplo de norma de eficácia contida, prevista no art. 5.º, XIII, e que tem como bom exemplo a restrição, por meio de lei, exigindo-se a aprovação no Exame de Ordem para o exercício da advocacia. Finalmente, a <i>letra “e”</i> reproduz a regra contida no art. 7.º, XIII, de eficácia contida, com a permissão para restrição de sua amplitude por meio de autorização da própria Constituição, ao se autorizar a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
25. “e”. Trata-se de direito fundamental previsto no art. 5.º, V, e que, mesmo com a revogação da lei de imprensa, em razão de sua não recepção pelo novo ordenamento, conforme decidiu o STF (cf. ADPF 130), referido direito pode ser exercido independentemente de regulamentação infraconstitucional, em razão de sua eficácia plena. A <i>letra “a”</i> reproduz o art. 7.º, XXI, de eficácia limitada e regulamentada pela Lei n. 12.506/2011: “aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei”. A <i>letra “b”</i> transcreve a regra do art. 37, VII, de eficácia limitada, tendo sido referido direito reconhecido em várias decisões do STF por meio de <i>mandado de injunção</i>: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. A <i>letra “c”</i> traz regra de eficácia limitada prevista no art. 5.º, LXXVII, e também já regulamentada nos termos da Lei n. 9.265/96: “são gratuitas as ações de <i>habeas corpus</i> e <i>habeas data</i>, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”. Finalmente, a <i>letra “d”</i> estabelece norma prevista no 5.º, XXXII, de eficácia limitada e que foi regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

26. “certo”.
27. “a”.
28. “b”. Os dois dispositivos (art. 211, <i>caput</i> , e art. 5.º, XIII, da CF/88) foram expressamente citados na parte teórica.
29. “certo”.
30. “c”.
31. “certo”.
32. “b”. Nesse sentido, a S. 648/STF estabelece que referida norma tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar e, portanto, era considerada norma de eficácia limitada.
33. “certo”. Trata-se do art. 7.º, XI, da CF/88: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”.
34. “certo”. Trata-se do art. 230, § 2.º, da CF/88: “Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos”.
35. “certo”.
36. “errado”. Trata-se de norma de eficácia contida (art. 37, I) em relação aos brasileiros. Em relação aos estrangeiros (como indicado no quadro — <i>item 5.9</i>), é norma de eficácia limitada (nesse sentido, cf. José Afonso da Silva, <i>Comentário contextual à Constituição</i> , 8. ed., p. 342-343). A norma do art. 207, 1.º, é também de eficácia limitada em relação aos estrangeiros (“na forma da lei”).
37. “certo”. Art. 215, CF/88. Na parte teórica, denominamos de norma de eficácia limitada, declaratória de princípios programáticos.
38. “errado”. Cf. <i>item 5.5</i> .
39. “errado”. A norma contida no art. 5.º, VII (“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de

complementar, quando, no caso, o direito é balizado por lei ordinária.

40. “c”. Esse, inclusive, o posicionamento no STF no julgamento do RE 161.547 (cf. *item 5.9*).

41. “errado”. Conforme visto na parte teórica, o STF, ao analisar o art. 5.º, XIII, CF/88, estabeleceu que “nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional (RE 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.08.2011, Plenário, *DJE* de 10.10.2011). Assim, o *erro* da questão está em afirmar que a restrição normativa poderá se dar para todos os ofícios ou profissões. Para se ter um exemplo, o STF entendeu que a profissão de músico é livre, não podendo haver restrição normativa.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

■ 6.1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: DIREITO COMPARADO E SISTEMA BRASILEIRO¹

■ 6.1.1. Noções preliminares

O legislador constituinte originário criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na “Lei Maior”.

Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de uma **Constituição rígida** e a **atribuição de competência a um órgão** para resolver os problemas de constitucionalidade, órgão esse que variará de acordo com o sistema de controle adotado.

Conforme já estudado, **Constituição rígida** é aquela que possui um processo de alteração mais dificultoso, mais árduo, mais solene que o processo legislativo de alteração das normas não constitucionais. A CF brasileira é rígida, diante das regras procedimentais solenes de alteração previstas em seu art. 60.

A ideia de controle, então, emanada da rigidez, pressupõe a noção de um **escalonamento normativo**, ocupando a Constituição o grau máximo na aludida relação hierárquica, caracterizando-se como **norma de validade** para os demais atos normativos do sistema.

Trata-se do **princípio da supremacia da Constituição**, que, nos dizeres do

Professor José Afonso da Silva, reputado por Pinto Ferreira como “pedra angular, em que assenta o edifício do moderno direito político”, “significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as *normas fundamentais* de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas”. Desse princípio, continua o mestre, “resulta o da *compatibilidade vertical* das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é a Constituição. As que não forem compatíveis com ela são inválidas, pois a *incompatibilidade vertical* resolve-se em favor das normas de grau mais elevado, que funcionam como fundamento de validade das inferiores”.²

A Constituição está, pois, no ápice da pirâmide, orientando e “iluminando” os demais atos infraconstitucionais.

Alertamos que há uma tendência a ampliar o conteúdo do parâmetro de constitucionalidade de acordo com aquilo que a doutrina vem chamando de bloco de constitucionalidade (cf. análise no *item 6.7.1.3*).

■ 6.1.2. A inconstitucionalidade das leis e a regra geral da “teoria da nulidade”. Sistema austríaco (Kelsen) *versus* Sistema norte-americano (Marshall). Anulabilidade *versus* nulidade

Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização da **teoria da nulidade** ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o **plano da validade**).

Trata-se, nesse sentido, de ato **declaratório** que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento” do ato normativo.

A ideia de a lei ter “nascido morta” (*natimorta*), já que existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade (em razão de vício formal ou material) em relação à noção de “bloco de constitucionalidade” (ou paradigma de controle), consagra a **teoria da nulidade**, afastando a incidência da teoria da anulabilidade.

Assim, o ato legislativo, por regra, uma vez declarado inconstitucional, deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, “... nulo, írrito, e, portanto, desprovido de força vinculativa”.³

A doutrina tradicional já se manifestava nessa linha, destacando-se os ensinamentos de Rui Barbosa,⁴ Alfredo Buzaid,⁵ Castro Nunes⁶ e Francisco Campos.⁷

Cappelletti, ao descrever o sistema “norte-americano”, observa que “... a lei inconstitucional, porque contrária a uma *norma superior*, é considerada *absolutamente nula* (‘null and void’) e, por isto, *ineficaz*, pelo que o juiz, que exerce o poder de controle, não anula, mas, meramente, *declara (preexistente) nulidade da lei inconstitucional*”.⁸

Contra esse entendimento, destaca-se a **teoria da anulabilidade da norma inconstitucional** defendida por Kelsen⁹ e que influenciou a Corte Constitucional austríaca, caracterizando-se como constitutiva a natureza jurídica da decisão que a reconhece.¹⁰

Segundo Cappelletti, no **sistema austríaco**, diferentemente do sistema norte-americano da nulidade, “... a Corte Constitucional não declara uma nulidade, mas *anula, cassa* (‘aufhebt’) uma lei que, até o momento em que o pronunciamento da Corte não seja publicado, é *válida e eficaz*, posto que inconstitucional (*sic*). Não é só: mas — coisa ainda mais notável — a Corte Constitucional austríaca tem, de resto, o poder discricionário de dispor que a anulação da lei opere somente a partir de uma determinada data *posterior* (‘Kundmachung’) de seu pronunciamento, contanto que este diferimento de eficácia constitutiva do pronunciamento não seja superior a um ano...”.¹¹

Na linha da **teoria da anulabilidade** da lei inconstitucional (ineficácia a partir da decisão), no **Brasil**, em sede doutrinária e minoritária, destacam-se Pontes de Miranda¹² e Regina Nery Ferrari.¹³

A confrontação dos sistemas pode ser assim esquematizada:

SISTEMA AUSTRIÁCO (KELSEN)	SISTEMA NORTE-AMERICANO (MARSHALL)
■ decisão tem eficácia constitutiva (caráter constitutivo-negativo)	■ decisão tem eficácia declaratória de situação preexistente
■ por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da eficácia	■ por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da validade
■ por regra, decisão que reconhece a inconstitucionalidade produz efeitos ex nunc (prospectivos)	■ por regra, decisão que declara a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc (retroativos)
■ a lei inconstitucional é ato anulável (a anulabilidade pode aparecer em vários graus)	■ a lei inconstitucional é ato nulo (null and void), ineficaz (nulidade ab origine), írrito e, portanto, desprovido de força vinculativa
■ lei provisoriamente válida , produzindo efeitos até a sua anulação	■ invalidação ab initio dos atos praticados com base na lei inconstitucional, atingindo-a no berço
■ o reconhecimento da ineficácia da lei produz efeitos a partir da decisão ou para o futuro (ex nunc ou pro futuro), sendo erga omnes, preservando-se, assim, os efeitos produzidos até então pela lei	■ a lei, por ter nascido morta (natimorta), nunca chegou a produzir efeitos (não chegou a viver), ou seja, apesar de existir, não entrou no plano da eficácia

Esse quadro representa tanto a teoria da nulidade (que prevalece na realidade brasileira) como a da anulabilidade em seus extremos. Ao longo dos tempos, doutrina e jurisprudência procuraram flexibilizá-las. É o que passamos a estudar.

■ 6.1.3. Flexibilização das teorias da “nulidade absoluta da lei declarada inconstitucional” e da “anulabilidade da norma inconstitucional” no direito estrangeiro (brevíssima noção)

Cappelletti observa que tanto o rigor da regra da **não retroatividade** do sistema austríaco como o da técnica da **nulidade absoluta** do sistema norte-americano tiveram de ser reavaliados, visto que insubsistentes. [14](#)

■ 6.1.3.1. *Áustria*

Em relação à **Áustria**, em 1929, a regra que negava qualquer retroatividade às decisões e pronunciamentos da Corte Constitucional foi atenuada, fixando-se a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à decisão anulatória.

Regina Ferrari observa que “o efeito voltado para o futuro — *ex nunc* — é o normal das sentenças constitutivas, mas não pertence à sua essência: o essencial é a produção de um estado jurídico que não existia antes de tal decisão”.

Conclui em seguida que “... a norma inconstitucional é anulável e os atos praticados sob o império dessa lei devem ser considerados válidos, até e enquanto não haja decisão que a fulmine com tal vício, operando eficaz e normalmente como qualquer outra disposição válida, já que o é até a decretação de inconstitucionalidade”. Finalmente, admite que referida sentença pode ter alcance *ex tunc*. [15](#)

■ 6.1.3.2. *Estados Unidos*

Quanto à técnica “fria” da nulidade *ab origine* (de origem norte-americana — “*the unconstitutional statute is not law at all*” [16](#) — e adotada no Brasil),

Cappelletti passa a imaginar situações práticas que apontariam a sua inadequação.

Como ficariam todos os atos praticados, durante longos anos, sob a vigência de uma lei que venha a ser declarada inconstitucional? Como resolver a questão de um contrato que tenha sido celebrado e servido de base para a prestação de um serviço público por longos anos? Como ficarão os efeitos da lei? Como sustentar o cumprimento de uma pena que tenha fundamento em lei que venha a ser declarada inconstitucional? Que fazer com os efeitos já consolidados? E a coisa julgada? E o mínimo de certeza e estabilidade que todas as relações jurídicas devem ter?

Nos **Estados Unidos**, o precedente lembrado é o caso *Likletter v. Walker*, em relação ao qual, realizando análise política, a Suprema Corte entendeu que o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei que permitia certo sistema de colheita de provas não retroagiria para invalidar decisões já tomadas com base naquele sistema.

Conforme relatado por Gilmar Mendes,¹⁷ toda a polêmica decorreu do julgamento do caso *Mapp v. Ohio* 367 US 643 (1961), no qual a Suprema Corte entendeu, nos termos da 4.^a Emenda, que a prova obtida ilegalmente não poderia ser considerada no juízo penal, seja nas Cortes Federais, como também, e inovando, nas Estaduais, superando-se a doutrina fixada em *Wolf v. Colorado*, 338 US 25 (1949).

O objetivo era desestimular “ações ilegais da polícia, proteger a privacidade das vítimas e ensejar que os órgãos federais e estaduais operassem com base nos mesmos padrões jurídicos”. Contudo, à decisão não foi atribuído efeito retroativo, para evitar, segundo o Juiz Clark, a quebra de confiança depositada em *Wolf v. Colorado* e impor “desmedida carga de trabalho para a administração da Justiça”.¹⁸

Assim, o pedido de se considerar ilegal, no caso *Likletter v. Walker*, a obtenção da prova por arrombamento, agora com base no novo precedente fixado em *Mapp v. Ohio*, foi indeferido para evitar sério problema de administração de justiça (e a perspectiva de diversos pedidos no mesmo sentido

de revisão), surgindo, pois, uma importante atenuação ao rígido princípio da nulidade absoluta da lei. [19](#)

Parafraseando Sérgio Resende de Barros, parecia estar sendo desatado o “nó górdio” do sistema de controle, flexibilizando o sistema da nulidade absoluta e se permitindo a **modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade**. [20](#)

■ 6.1.3.3. Espanha

Garcia de Enterría, na **Espanha**, destaca a hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e *pro futuro* tendo como precedente a **Sentença n. 45/1989**. [21](#)

■ 6.1.3.4. Portugal

Em **Portugal**, muito embora a declaração de nulidade da lei inconstitucional seja a regra geral, há expressa autorização constitucional permitindo a modulação dos efeitos da decisão, bem como a desconstituição da coisa julgada em matérias específicas e desde que haja expressa determinação pelo Tribunal Constitucional.

■ 6.1.3.5. Alemanha

Na **Alemanha**, o princípio da nulidade da lei inconstitucional está consagrado como regra geral, nos termos do § 78 da Lei do *Bundesverfassungsgericht*.

Contudo, ensina Gilmar Mendes, várias técnicas surgem no sentido de resolver alguns problemas trazidos pela rigidez do princípio da nulidade (que é reconhecido como constitucional, como visto), destacando-se o “**apelo ao legislador**” ou “**situação ainda constitucional**” (*Appellentscheidung*) [22](#) e a **declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade** (*Unvereinbarkeitserklärung* — omissão parcial; exclusão de benefício incompatível com o princípio da isonomia; [23](#) ameaça de caos jurídico, lacunas

ameaçadoras etc.). [24](#)

■ 6.1.4. Flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro

A regra geral da nulidade absoluta da lei inconstitucional vem sendo, casuisticamente, afastada pela jurisprudência brasileira e repensada pela doutrina.

Ao lado do **princípio da nulidade**, que adquire, certamente, o *status* de **valor constitucionalizado**, tendo em vista o princípio da **supremacia da Constituição**, outros valores, de igual hierarquia, destacam-se, por exemplo, o princípio da **segurança jurídica** e o da **boa-fé**.

Nesses termos, valendo-se da evolução da jurisprudência norte-americana, Lúcio Bittencourt afirma que a “... doutrina da *ineficácia ab initio* da lei inconstitucional não pode ser entendida em termos absolutos, pois que os efeitos *de fato* que a norma produziu não podem ser suprimidos, sumariamente, por simples obra de um decreto judiciário”. [25](#)

■ 6.1.4.1. A mitigação do princípio da nulidade no controle concentrado — art. 27 da Lei n. 9.868/99 e art. 11 da Lei n. 9.882/99

Toda evolução e movimento verificados no direito estrangeiro também foram considerados no Brasil, que “legalizou” a tendência jurisprudencial que já vinha sendo percebida, muito embora lentamente, a flexibilizar a rigidez do princípio geral — e que ainda é regra, diga-se de passagem — da **nulidade** da lei declarada inconstitucional no controle concentrado.

Nesse sentido, com bastante propriedade, estabelece o **art. 27 da Lei n. 9.868/99**:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, **restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia**

a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser **fixado** (no mesmo sentido, cf. art. 11 da Lei n. 9.882/99 — ADPF).

Trata-se da denominada, pela doutrina, técnica de **modulação dos efeitos da decisão** e que, nesse contexto, permite uma melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, assegurando, por consequência, outros valores também constitucionalizados, como os da **segurança jurídica**, do **interesse social** e da **boa-fé**.

■ 6.1.4.2. A mitigação do princípio da nulidade no controle difuso

A regra geral do art. 27 da Lei n. 9.868/99, em casos particulares, também tem sido aplicada, por analogia, ao controle difuso.

Em importante precedente, destaca-se ação civil pública ajuizada pelo MP de São Paulo objetivando reduzir o número de vereadores do Município de **Mira Estrela**, de 11 para 9, adequando-se ao mínimo constitucional previsto no art. 29, IV, da CF/88. Pouco razoável seria um Município com 2.651 habitantes ter 11 vereadores, 2 além do mínimo constitucional.

O MP de São Paulo pedia a **devolução dos subsídios indevidamente pagos** e a **declaração incidental da inconstitucionalidade da lei** (controle difuso), com efeitos **retroativos**.

Porém, conforme ponderou o Min. Maurício Corrêa na parte final de seu voto, “... a declaração de nulidade com os ordinários efeitos *ex tunc* da composição da Câmara representaria um **verdadeiro caos quanto à validade**, não apenas, em parte, das eleições já realizadas, mas dos atos legislativos praticados por esse órgão sob o manto presuntivo da legitimidade. Nessa situação específica, tenho presente excepcionalidade tal a justificar que a presente decisão prevaleça **tão somente para as legislaturas futuras**, assegurando-se a prevalência, no caso, do sistema até então vigente em nome da segurança jurídica...”.²⁶

Partindo desse precedente, interessante a análise de tantos outros julgados no sentido de se **modular os efeitos da decisão** também no controle difuso,

destacando-se os julgamentos do **RE-AgR 434.222/AM** e do **MS 22.357/DF**.

O STF, portanto, à luz do **princípio da segurança jurídica**, do **princípio da confiança**, da **ética jurídica**, da **boa-fé**, todos **constitucionalizados**, em verdadeira **ponderação de valores**, vem, casuisticamente, mitigando os efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade das leis também no controle difuso, preservando-se situações pretéritas consolidadas com base na lei objeto do controle.

Sem dúvida, de maneira coerente, imprescindível essa tendência de **mitigação do princípio da nulidade**, tanto em sede de controle concentrado como em sede de controle difuso.

■ 6.2. BREVE ANÁLISE EVOLUTIVA DO SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE [27](#)

■ 6.2.1. Constituição de 1824

No tocante ao **sistema brasileiro de controle de constitucionalidade**, [28](#) a Constituição Imperial de 1824 não estabeleceu nenhum sistema de controle, consagrando o **dogma da soberania do Parlamento**, já que, sob a influência do direito francês (*a lei como “expressão da vontade geral”*) e do inglês (*supremacia do Parlamento*), somente o Órgão Legislativo poderia saber o verdadeiro sentido da norma.

No entanto, nas precisas palavras de Clémerson Merlin Clève, “não foi apenas o dogma da soberania do Parlamento que impediu a emergência da fiscalização jurisdicional da constitucionalidade no Império. O Imperador, enquanto detentor do Poder Moderador, exercia uma função de coordenação; por isso, cabia a ele (art. 98) manter a ‘independência, o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes’. Ora, o papel constitucional atribuído ao Poder Moderador, ‘chave de toda a organização política’ nos termos da Constituição, praticamente inviabilizou o exercício da função de fiscalização constitucional pelo Judiciário. Sim, porque, nos termos da Constituição de 1824, ao Imperador

cabia solucionar os conflitos envolvendo os Poderes, e não ao Judiciário”. Portanto, completa o ilustre jurista, “o dogma da ‘soberania do Parlamento’, a previsão de um Poder Moderador e mais a influência do direito público europeu, notadamente inglês e francês, sobre os homens públicos brasileiros, inclusive os operadores jurídicos, explicam a inexistência de um modelo de fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das leis no Brasil ao tempo do Império”.[29](#)

■ 6.2.2. Constituição de 1891

A partir da Constituição Republicana de 1891, sob a influência do direito norte-americano, consagra-se, no direito brasileiro, mantida até a CF/88, a técnica de controle de constitucionalidade de lei ou ato com indiscutível caráter normativo (desde que infraconstitucionais), por qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência e organização judiciária. Trata-se do denominado **controle difuso** de constitucionalidade, repressivo, posterior, ou aberto, pela via de exceção ou defesa, pelo qual a declaração de inconstitucionalidade se implementa de modo incidental (*incidenter tantum*), prejudicialmente ao mérito.[30](#)

■ 6.2.3. Constituição de 1934

A **Constituição de 1934**, mantendo o sistema de controle difuso, estabeleceu, além da **ação direta de inconstitucionalidade interventiva**, a denominada **cláusula de reserva de plenário** (a declaração de inconstitucionalidade só poderia ser pela **maioria absoluta** dos membros do tribunal) e a atribuição ao **Senado Federal** de competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato declarado inconstitucional por decisão definitiva.

Asseverou Gilmar Ferreira Mendes, ao comentar as novidades trazidas pela Constituição de 1934 em relação ao sistema de controle de constitucionalidade, que “talvez a mais fecunda e inovadora alteração (...) se refira à ‘declaração de

inconstitucionalidade para evitar a intervenção federal’, tal como a denominou Bandeira de Mello, isto é, a representação interventiva, confiada ao Procurador-Geral da República, nas hipóteses de ofensa aos princípios consagrados no art. 7.º, I, *a a h*, da Constituição. Cuidava-se de fórmula peculiar de composição judicial dos conflitos federativos, que condicionava a eficácia da lei interventiva, de iniciativa do Senado (art. 41, § 3.º), à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal (art. 12, § 2.º)”.[31](#)

■ 6.2.4. Constituição de 1937

A **Constituição de 1937**, denominada **Polaca**, já que elaborada sob a inspiração da Carta ditatorial polonesa de 1935, não obstante tenha mantido o sistema difuso de constitucionalidade, estabeleceu a possibilidade de o Presidente da República influenciar as decisões do Poder Judiciário que declarassem inconstitucional determinada lei, já que, **de modo discricionário**, poderia submetê-la ao Parlamento para o seu reexame, podendo o Legislativo, pela decisão de 2/3 de ambas as Casas, tornar sem efeito a declaração de inconstitucionalidade, desde que confirmasse a validade da lei.[32](#) Referidas regras, inegavelmente, implicavam o desproporcional fortalecimento do Executivo.

■ 6.2.5. Constituição de 1946

A **Constituição de 1946**, fruto do movimento de redemocratização e reconstitucionalização instaurado no País, flexibilizou a hipertrofia do Executivo, restaurando a tradição do sistema de controle de constitucionalidade. Através da **EC n. 16, de 26.11.1965**, criou-se no Brasil uma nova modalidade de **ação direta de inconstitucionalidade**, de competência originária do STF, para processar e julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, a ser proposta, exclusivamente, pelo Procurador-Geral da República. Estabeleceu-se, ainda, a possibilidade de

controle concentrado em âmbito estadual.

■ 6.2.6. Constituição de 1967 e EC n. 1/69

Esta última regra foi retirada pela **Constituição de 1967**, embora a **EC n. 1/69** tenha previsto o controle de constitucionalidade de lei municipal, em face da Constituição Estadual, para fins de intervenção no Município.

■ 6.2.7. Constituição de 1988

A **Constituição de 1988**, elaborada pela *Assembleia Nacional Constituinte* convocada pela **EC n. 26, de 27.11.1985**³³ (DOU de 28.11.1985, p. 17422, col. 1), trouxe quatro principais novidades no sistema de controle de constitucionalidade.

Em relação ao controle concentrado em âmbito federal, **ampliou a legitimação para a propositura da representação de inconstitucionalidade**, acabando com o monopólio do Procurador-Geral da República. Em consonância com o art. 103 da CF/88, o art. 2.º da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, legalizando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, dispõe que a ação direta de inconstitucionalidade poderá ser proposta pelos seguintes legitimados: *Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional*.

Estabeleceu-se, também, a possibilidade de **controle de constitucionalidade das omissões legislativas**, seja de forma concentrada (*ações diretas de inconstitucionalidade por omissão — ADO*, nos termos do art. 103, § 2.º), seja de modo incidental, pelo controle difuso (*mandado de injunção — MI*, na dicção do art. 5.º, LXXI — sobre a evolução da utilização do mandado de injunção, cf.

item 14.11.5).

Nos termos do art. 125, § 2.º, os **Estados** poderão instituir a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedando, contudo, a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Por fim, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, facultou-se a criação da **arguição de descumprimento de preceito fundamental** (ADPF), no parágrafo único do art. 102.

Posteriormente, a **EC n. 3/93** estabeleceu a **ação declaratória de constitucionalidade** (ADC)³⁴ e reenumerou o parágrafo único do art. 102 da CF/88, transformando-o em § 1.º, mantendo a redação original da previsão da ADPF, nos seguintes termos: “a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.

Enfim, a **EC n. 45/2004** (Reforma do Judiciário) ampliou a legitimação ativa para o ajuizamento da ADC (ação declaratória de constitucionalidade), igualando aos legitimados da ADI (ação direta de inconstitucionalidade), alinhados no art. 103, e estendeu o efeito vinculante, que era previsto de maneira expressa somente para a ADC, agora, também (apesar do que já dizia o art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 e da jurisprudência do STF), para a ADI. Tudo caminha para a expressa consagração da ideia de efeito dúplice ou ambivalente entre as duas ações, faltando somente a igualação dos seus objetos.

Por todo o exposto, valendo-nos das palavras de José Afonso da Silva, “o Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema misto e peculiar que combina o critério difuso por via de defesa com o critério concentrado por via de ação direta de inconstitucionalidade, incorporando também, agora timidamente, a ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, I, *a* e III, e 103). A outra novidade está em ter reduzido a competência do Supremo Tribunal Federal à matéria constitucional. Isso não o converte em Corte Constitucional. Primeiro porque não é o único órgão jurisdicional competente para o exercício da jurisdição constitucional, já que o sistema

perdura fundado no critério difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz a conhecer da prejudicial de inconstitucionalidade, por via de exceção. Segundo, porque a forma de recrutamento de seus membros denuncia que continuará a ser um Tribunal que examinará a questão constitucional com critério puramente técnico-jurídico, mormente porque, como Tribunal, que ainda será, do recurso extraordinário, o modo de levar a seu conhecimento e julgamento as questões constitucionais nos casos concretos, sua preocupação, como é regra no sistema difuso, será dar primazia à solução do caso e, se possível, sem declarar inconstitucionalidades”.[35](#)

■ 6.3. ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE

■ 6.3.1. Inconstitucionalidade por ação e por omissão (quadro esquemático)

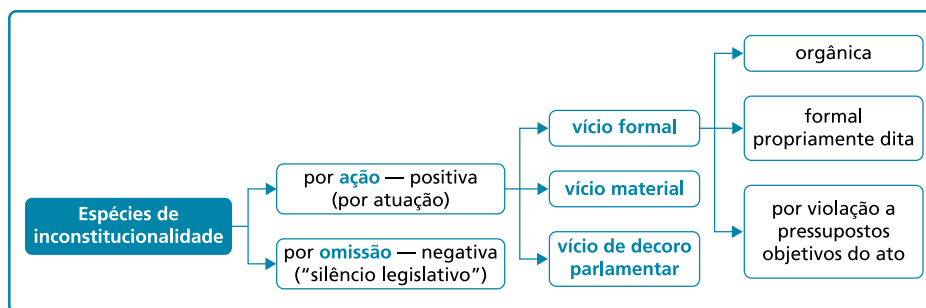
O que se busca com esse tema é saber quando uma norma infraconstitucional padecerá do vício de inconstitucionalidade, que poderá verificar-se em razão de ato **comissivo** ou por **omissão** do Poder Público.

Fala-se, então, em inconstitucionalidade por **ação** (positiva ou por atuação), a ensejar a **incompatibilidade vertical** dos atos inferiores (leis ou atos do Poder Público) com a Constituição,[36](#) e, em sentido diverso, em inconstitucionalidade por **omissão**, decorrente da inércia legislativa na regulamentação de normas constitucionais de **eficácia limitada**.

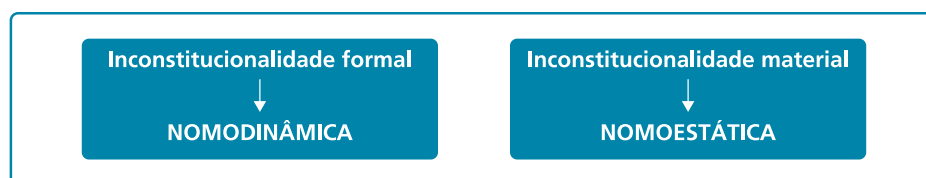
Para Canotilho, enquanto a inconstitucionalidade por **ação** pressupõe a existência de normas inconstitucionais, a inconstitucionalidade por **omissão** pressupõe a “violação da lei constitucional pelo *silêncio legislativo* (violação por omissão)”.[37](#)

Particularizando, a inconstitucionalidade por **ação** pode-se dar: *a)* do ponto de vista **formal**; *b)* do ponto de vista **material**; *c)* e estamos pensando em uma terceira forma em razão dos escândalos dos denominados “mensalão” e “mensalinho” para votar em um sentido ou em outro, “batizada” de “**vício de**

decoro parlamentar”.³⁸



No tocante ao vício **formal** e **material**, a doutrina também tem distinguido as expressões **nomodinâmica** e **nomoestática**, respectivamente, para a inconstitucionalidade.³⁹ Na medida em que o *vício formal* decorre de afronta ao *devido processo legislativo* de formação do ato normativo, isso nos dá a ideia de *dinamismo*, de movimento. Por sua vez, o *vício material*, por ser um vício de matéria, de conteúdo, a ideia que passa é de vício de substância, estático.



■ 6.3.2. Vício formal (inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato)

Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como **nomodinâmica**, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.

Segundo Canotilho, os vícios formais “... incidem sobre o *ato normativo enquanto tal*, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese *inconstitucionalidade formal*, viciado é o *ato*, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma

final”.[40](#)

Podemos, então, falar em **inconstitucionalidade formal orgânica**, em **inconstitucionalidade formal propriamente dita** e em **inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato**.

■ 6.3.2.1. *Inconstitucionalidade formal orgânica*

A inconstitucionalidade formal **orgânica** decorre da inobservância da **competência legislativa** para a elaboração do ato.

Para se ter um exemplo, o STF entende inconstitucional lei municipal que discipline o uso do cinto de segurança, já que se trata de competência da União, nos termos do art. 22, XI, legislar sobre trânsito e transporte.

Outro exemplo, dentre tantos já apreciados pelo STF (cf. *item 7.10* desta obra), foi assim ementado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que regula obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei n. 11.446/1997, do Estado de Pernambuco). *Vício formal*. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros (CF, art. 22, I e VII). Precedente: ADI n. 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, *DJ* 19/12/02, Pleno, maioria” (ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.08.2006, *DJ* de 07.12.2006). No mesmo sentido: ADI 1.595, Rel. Min. Eros Grau, j. 03.03.2005, *DJ* de 07.12.2006.

■ 6.3.2.2. *Inconstitucionalidade formal propriamente dita*

Por sua vez, a inconstitucionalidade **formal propriamente dita** decorre da inobservância do **devido processo legislativo**. Podemos falar, então, além de vício de competência legislativa (inconstitucionalidade orgânica), em vício no procedimento de elaboração da norma, verificado em momentos distintos: na **fase de iniciativa** ou nas **fases posteriores**.[41](#)

Vício formal subjetivo: o vício formal subjetivo verifica-se na fase **de**

iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de *iniciativa exclusiva (reservada)*⁴² do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.º, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, **exclusiva** ou **reservada**, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional.

Vício formal objetivo: por seu turno, o vício formal objetivo será verificado nas demais fases do processo legislativo, posteriores à fase de iniciativa. Como exemplo citamos uma lei complementar sendo votada por um *quorum* de maioria relativa. Existe um vício formal objetivo, na medida em que a lei complementar, por força do art. 69 da CF/88, deveria ter sido aprovada por maioria absoluta.

Outro exemplo seria uma PEC votada com *quorum* diferente do previsto no art. 60, § 2.º (3/5 em cada Casa e em 2 turnos de votação). Se isso ocorrer, a emenda promulgada padecerá de vício formal objetivo de inconstitucionalidade.

Outra hipótese seria a violação ao princípio do bicameralismo federativo. Como se sabe, os projetos de lei federal devem ser aprovados nas duas Casas do Congresso Nacional — Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Se, eventualmente, projeto de lei for modificado **em sua substância** pela Casa revisora, terá a emenda de voltar para a análise da Casa iniciadora, sob pena de configurar o vício formal objetivo.

Nesse ponto, a denominada **“emenda de redação”** pode existir na Casa revisora, mas desde que não signifique substancial modificação do texto aprovado na Casa iniciadora. Se isso ocorrer, terá de voltar para a análise da outra Casa (art. 65, parágrafo único), sob pena de se configurar o vício formal objetivo.

■ 6.3.2.3. *Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos*

objetivos do ato normativo

Segundo Canotilho, “hoje, põe-se seriamente em dúvida se certos elementos tradicionalmente não reentrantes no processo legislativo não poderão ocasionar vícios de inconstitucionalidade. Estamos a referir-nos aos chamados pressupostos, constitucionalmente considerados como elementos determinantes de competência dos órgãos legislativos em relação a certas matérias (pressupostos objectivos)”.[43](#)

Exemplificando, o autor lembra o art. 229, 2.º, da Constituição portuguesa, que determina a audiência obrigatória, pelos órgãos de soberania, dos órgãos do governo regional, quanto a questões relativas às regiões autónomas, sob pena de faltar um pressuposto para o exercício da competência e, assim, caracterizar-se irregularidade do ato.

Nesse caso, a audiência e participação obrigatórias “... são elementos externos ao procedimento de formação das leis...”, e a sua falta gera a **inconstitucionalidade formal**, já que os **pressupostos** do ato legislativo devem ser entendidos como “elementos vinculados do *ato* legislativo”.[44](#)

Transportando a teoria de Canotilho para o direito brasileiro, valemo-nos de exemplos trazidos por Clèmerson Merlin Clève, quais sejam, a edição de medida provisória sem a observância dos requisitos da relevância e urgência (art. 62, *caput*) ou a criação de Municípios por lei estadual sem a observância dos requisitos do art. 18, § 4.º.

Neste último exemplo, o ilustre professor observa que a “... lei estadual dispendo sobre a criação de novo Município, ainda que regularmente votada e sancionada, mas sem observar o pressuposto referido, estará maculada por inafastável vício de inconstitucionalidade formal. O mesmo se verifica no caso do art. 18, § 3.º, da Lei Fundamental da República”.[45](#)

Também concordamos com esse pensamento. O tema foi apreciado no julgamento da **ADI 2.240**, na qual se discutia a constitucionalidade da lei baiana n. 7.619/2000, que criou o Município de *Luís Eduardo Magalhães*, sem a total observância dos pressupostos fixados no art. 18, § 4.º. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, mas não pronunciou a

nulidade do ato, mantendo sua vigência por mais 24 meses (**efeito prospectivo** ou para o futuro), tema que será retomado no *item 6.7.1.9* deste trabalho. Cabe lembrar que a **EC n. 57/2008** convalidou a criação de vários Municípios, em nosso entender, de modo inconstitucional, ilegítimo e até imoral (cf. *item 6.7.4.9*).

■ 6.3.3. Vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário)

Por seu turno, o vício **material** (de conteúdo, substancial ou doutrinário) diz respeito à “matéria”, ao conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato normativo que afrontar qualquer preceito ou princípio da Lei Maior deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material. Não nos interessa saber aqui o procedimento de elaboração da espécie normativa, mas, de fato, o seu conteúdo. Por exemplo, uma lei discriminatória que afronta o princípio da igualdade.

Nas palavras de Barroso, “a inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Pode traduzir-se no confronto com uma **regra constitucional** — *e.g.*, a fixação da remuneração de uma categoria de servidores públicos acima do limite constitucional (art. 37, XI) — ou com um **princípio constitucional**, como no caso de lei que restrinja ilegítimamente a participação de candidatos em concurso público, em razão do sexo ou idade (arts. 5.º, *caput*, e 3.º, IV), em desarmonia com o mandamento da isonomia. O controle material de constitucionalidade pode ter como parâmetro todas as categorias de normas constitucionais: de organização, definidoras de direitos e programáticas”.⁴⁶

A inconstitucionalidade material é também conhecida como **nomoestática**.⁴⁷

Observamos que uma lei pode padecer somente de vício formal, somente de vício material, ou ser duplamente inconstitucional por apresentar tanto o vício formal como o material.

■ 6.3.4. Vício de decoro parlamentar (?)

Como se sabe e foi publicado em jornais, revistas etc., muito se falou em um esquema de compra de votos, denominado “mensalão”, para votar de acordo com o governo ou em certo sentido.

As CPIs vêm investigando e a Justiça apurando, e, uma vez provados os fatos, os culpados deverão sofrer as sanções de ordem criminal, administrativa, civil etc.

O grande questionamento que se faz, contudo, é se, uma vez comprovada a existência de compra de votos, haveria mácula no processo legislativo de formação das **emendas constitucionais** a ensejar o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.

Entendemos que **sim**, e, no caso, trata-se de **vício de decoro parlamentar**, já que, nos termos do art. 55, § 1.º, “é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o **abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional** ou a **percepção de vantagens indevidas**”.

Dito isso, cabe lembrar que, no julgamento da **AP 470** (conhecida como “**mensalão**”), ficou demonstrado o **esquema de corrupção para compra de apoio político**.[48](#)

Como noticiado, “‘houve, efetivamente, a distribuição de milhões de reais a parlamentares que compuseram a base aliada do governo, distribuição essa executada mais direta e pessoalmente por Delúbio Soares, Marcos Valério e Simone Vasconcelos, como nós vimos nas últimas sessões de julgamento’, disse o **ministro-relator**. Ele afirmou que o responsável pela articulação da base aliada era José Dirceu, que se reunia frequentemente com líderes parlamentares que receberam dinheiro em espécie do Partido dos Trabalhadores para a aprovação de determinadas emendas constitucionais. O dinheiro, afirma o ministro, foi distribuído em espécie na agência do Banco Rural, em Brasília, ‘onde Simone Vasconcelos dispunha de uma sala reservada para a entrega do numerário aos parlamentares e aos seus intermediários’” (*Notícias STF* de 03.10.2012).

Ainda, de acordo com as *Notícias STF* de 04.10.2012, para a Ministra Rosa

Weber, “**‘houve, sem dúvida, um conluio’ para a compra de apoio de deputados federais** — não todos — para as votações a favor do governo na Câmara dos Deputados. O dinheiro, prossegue a ministra, veio de recursos, pelo menos em parte, públicos. Ela ressaltou que os parlamentares receberam dinheiro ilicitamente, ‘caso contrário o pagamento não teria ocorrido pela forma como foi feito, sempre às escondidas, mediante a utilização de terceiros e o recebimento de vultosos valores em espécie, inclusive malas em quartos de hotel’”.

E continua: “‘aos meus olhos, ficou evidente que o Partido dos Trabalhadores costumava alcançar dinheiro a outros partidos, entregando-o a parlamentares ou membros da organização partidária’, considerou a Ministra. Tal prática, conforme ela, ocorria para a **obtenção de apoio político no Parlamento**. ‘Disso, resulta a verossimilhança na descrição dos fatos pela denúncia. Foi criado um **esquema para pagar deputados federais em troca de seus votos na Câmara Federal e os valores eram expressivos**. Esses recursos tinham origem em peculato, em gestão fraudulenta do Banco Rural, em empréstimos simulados, foi o que se concluiu por este Plenário, ainda que por maioria’, completou a Min. Rosa Weber” (*Notícias STF* de 04.10.2012 — original sem grifos — cf. *Inf.* 682 e 683/STF).

Pois bem, diante do julgamento da citada AP 470, a *Associação dos Delegados de Polícia do Brasil* — ADEPOL (**ADI 4.887**), a *Confederação dos Servidores Públicos do Brasil* — CSPB (**ADI 4.888**) e o *Partido Socialismo e Liberdade* — PSOL (**ADI 4.889**) ajuizaram ADIs no STF objetivando a declaração de inconstitucionalidade da *Reforma da Previdência* (ECs ns. 41/2003 e 47/2005), alegando aprovação mediante compra de votos de parlamentares, liderados por réus condenados no “mensalão”, qual seja, o por nós denominado vício de decoro parlamentar.

A “tese” que lançamos no ano de **2005**, e já colocada neste nosso livro a partir de sua 9.^a edição, foi **admitida pela PGR** em seu parecer na ADI 4.887, tendo sido denominada “**vício na formação da vontade no procedimento legislativo**”, a ensejar a violação aos princípios democráticos e do devido

processo legislativo, implicando, necessariamente, a inconstitucionalidade do ato normativo (fls. 18 do parecer/PGR n. 10.323-RG, item 27).

Contudo, o posicionamento do MPF é no sentido da improcedência da ADI. Vejamos: “na ação penal 470, foram condenados 7 parlamentares em razão da sua participação no esquema de compra e venda de votos e apoio político que ficou conhecido como ‘mensalão’. Não se pode presumir, sem que tenha havido a respectiva condenação judicial, que outros parlamentares foram beneficiados pelo esquema e, em troca, venderam seus votos para a aprovação das ECs 41/2003 e 47/2005. Assim, mesmo com a desconsideração dos votos dos 7 deputados condenados, os dois turnos de votação das emendas constitucionais na Câmara dos Deputados superam o quórum qualificado exigido pela Constituição para a sua aprovação” (fls. 19 do parecer/MPF).

Vamos aguardar como o STF enfrentará essa importante questão. Em nosso entender, sem dúvida, o comprovado esquema de compra e venda de votos para se conseguir apoio político enseja o por nós denominado **vício de decoro parlamentar** a caracterizar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, pois que **maculados a essência do voto** e o conceito de **representatividade popular**. Nesse sentido, inclusive, concordou a PGR conforme visto acima. Teremos que aguardar se o STF vai considerar isoladamente os 7 votos dos parlamentares condenados (linha do parecer da PGR) ou a premissa exposta pela Ministra Rosa Weber de que o Partido dos Trabalhadores alimentava e incentivava o esquema a contaminar, como um todo, o procedimento ou, ao menos, a contaminar os votos dos parlamentares eleitos pela legenda e sua base aliada.

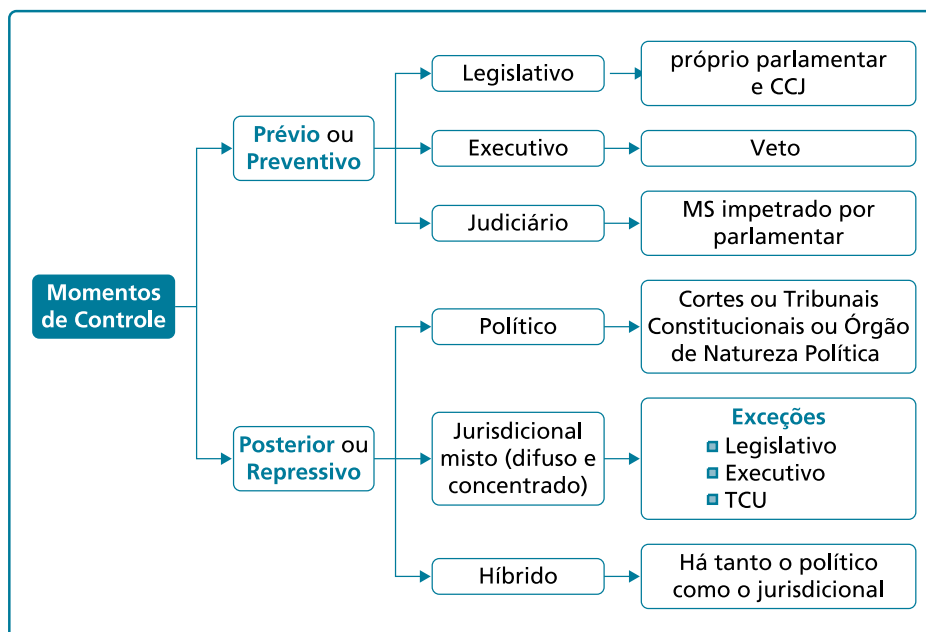
Esse sentido de uma contaminação mais ampla do procedimento parece poder ser extraído do julgamento da AP 470 que, ao identificar os focos do esquema, reconheceu a **capacidade de manipulação**, sugerindo-se uma **“contaminação” mais avassaladora**. Vejamos a ementa:

“**CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA**. SUBITENS VI.1, VI.2, VI.3 E VI.4. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PARLAMENTARES PARA

FORMAÇÃO DE ‘BASE ALIADA’ AO GOVERNO FEDERAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 5. Parlamentares beneficiários das transferências ilícitas de recursos **detinham poder de influenciar os votos de outros parlamentares de seus respectivos partidos, em especial por ocuparem as estratégicas funções de Presidentes de partidos políticos, de líderes parlamentares, líderes de bancadas e blocos partidários.** Comprovada a participação, no recebimento da propina, de intermediários da estrita confiança dos parlamentares, beneficiários finais do esquema. Depoimentos e recibos informais apreendidos no curso das investigações compõem as provas da prática criminosa” (AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, Plenário, DJE de 22.04.2013, fls. 51.626-51.629).

Sem dúvida, um grande tema, pendente de julgamento pelo STF!

■ 6.4. MOMENTOS DE CONTROLE



A classificação que passamos a analisar diz respeito ao momento em que será realizado o controle, qual seja, antes de o projeto de lei virar lei (**controle prévio** ou **preventivo**), impedindo a inserção no sistema normativo de normas que padeçam de vícios, ou já sobre a lei, geradora de efeitos potenciais ou efetivos (**controle posterior** ou **repressivo**).

■ 6.4.1. Controle prévio ou preventivo

Como vimos acima, o controle prévio é o realizado durante o **processo legislativo de formação do ato normativo**. Logo no momento da apresentação de um projeto de lei, o iniciador, a “pessoa” que deflagrar o processo legislativo, em tese, já deve verificar a regularidade material do aludido projeto de lei.

O controle prévio também é realizado pelo **Legislativo**, pelo **Executivo** e pelo **Judiciário**.

■ 6.4.1.1. Controle prévio ou preventivo realizado pelo legislativo

O legislativo verificará, através de suas **comissões de constituição e justiça**, se o projeto de lei, que poderá virar lei, contém algum vício a ensejar a inconstitucionalidade.

De acordo com o art. 32, IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o controle será realizado pela *Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania* (vide Res. da CD n. 20, de 2004 — *DCD*, de 18.03.2004, Suplemento, p. 3), enquanto no Senado Federal o controle será exercido pela *Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania* — *CCJ*, de acordo com o art. 101 de seu Regimento Interno. O plenário das referidas Casas também poderá verificar a inconstitucionalidade do projeto de lei, o mesmo podendo ser feito durante as votações.

Michel Temer observa que tal controle nem sempre se verifica em relação a todos os projetos de atos normativos, citando a sua inocorrência, por exemplo, sobre projetos de **medidas provisórias, resoluções dos Tribunais e decretos**.[49](#)

Questão interessante pode surgir indagando se o parecer negativo das Comissões de Constituição e Justiça, declarando a inconstitucionalidade do projeto de lei, inviabilizaria o seu prosseguimento.

O § 2.º do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal[50](#) dispõe que,

em se tratando de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício. No entanto, a regra geral é a do seu § 1.º, ao estabelecer que, quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada **rejeitada e arquivada definitivamente**, por despacho do Presidente do Senado, salvo, desde que não seja unânime o parecer, se houver recurso interposto nos termos do art. 254 do RI, ou seja, interposto por no mínimo **1/10** dos membros do Senado, manifestando opinião favorável ao seu processamento.

Da mesma forma, o art. 54, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados **51** estabelece que será “terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria” (inciso com redação adaptada à Resolução n. 20/2004). No entanto, há a previsibilidade de recurso para o plenário da Casa contra referida deliberação, nos termos dos arts. 132, § 2.º; 137, § 2.º; e 164, § 2.º, do referido Regimento Interno.

■ 6.4.1.2. *Controle prévio ou preventivo realizado pelo executivo*

Como veremos melhor ao estudar o processo legislativo, o Chefe do Executivo, aprovado o projeto de lei, poderá sancioná-lo (caso concorde) ou vetá-lo.

O veto dar-se-á quando o Chefe do Executivo considerar o projeto de lei **inconstitucional** ou **contrário ao interesse público**. O primeiro é o **veto jurídico**, sendo o segundo conhecido como **veto político**.

Assim, caso o Chefe do Executivo entenda ser inconstitucional o projeto de lei poderá vetá-lo, exercendo, desta feita, o controle de constitucionalidade **prévio ou preventivo**, antes de o projeto de lei transformar-se em lei.

Referido **veto**, necessariamente, nos termos do art. 66, § 4.º, da CF/88, será apreciado em **sessão conjunta** da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dentro de **30 dias** a contar de seu recebimento, podendo, pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores, em **votação ostensiva**, ou seja, por voto

“aberto” (lembramos que a **EC n. 76/2013** aboliu a votação secreta nessa hipótese), ser rejeitado (afastado), produzindo, nesse caso, os mesmos efeitos que a sanção.

Derrubado o veto, o projeto deverá ser enviado ao Presidente da República para **promulgação da lei** no prazo de 48 horas e, se este não o fizer, caberá ao Presidente do Senado Federal a promulgação, em igual prazo, e, caso este não a promulgue, caberá ao Vice-Presidente do Senado Federal fazê-lo (art. 66, § 7.º, da CF/88).

Na hipótese de o veto ser mantido, o projeto será arquivado, aplicando-se a regra contida no art. 67, que consagra o princípio da irrepetibilidade.

Imaginando a hipótese de **derrubada do veto** e a consequente **promulgação da lei**, naturalmente, a correspondente lei, ato normativo, poderá ser objeto de controle de constitucionalidade, agora, porém, o chamado *controle posterior* ou *repressivo*.

■ 6.4.1.3. **Controle prévio ou preventivo realizado pelo judiciário**

O controle prévio ou preventivo de constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário sobre PEC ou projeto de lei em trâmite na Casa Legislativa busca garantir ao **parlamentar** o respeito ao **devido processo legislativo**, vedando a sua participação em procedimento **desconforme com as regras da Constituição**. Trata-se, como visto, de controle exercido, no caso **concreto**, pela **via de exceção ou defesa**, ou seja, de modo incidental.

Assim, deve-se deixar claro que a legitimação para a impetração do MS é **exclusiva** do **parlamentar**, na medida em que o **direito público subjetivo** de participar de um *processo legislativo hígido* (**devido processo legislativo**) pertence somente aos **membros do Poder Legislativo**. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de **negar a legitimidade ativa *ad causam* a terceiros, que não ostentem a condição de parlamentar**, ainda que invocando a sua potencial condição de destinatários da futura lei ou emenda à Constituição, sob pena de indevida transformação em controle preventivo de

constitucionalidade em abstrato, inexistente em nosso sistema constitucional (*vide* *RTJ* 136/25-26, Rel. Min. Celso de Mello; *RTJ* 139/783, Rel. Min. Octavio Gallotti, e, ainda, MS 21.642-DF, MS 21.747-DF, MS 23.087-SP, MS 23.328-DF).

E a perda superveniente do mandato parlamentar?

Parece ter razão o Min. Celso de Mello ao afirmar que a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo **desqualifica a legitimação ativa do congressista**. Isso porque “... a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação **legitimante** e **necessária**, tanto para a **instauração** quanto para o **prosseguimento da causa** perante o STF. Inexistente, originariamente, essa situação, ou, como se registra no caso, configurada a ausência de tal condição, em virtude da **perda superveniente do mandato parlamentar** no Congresso Nacional, **impõe-se a declaração de extinção do processo de mandado de segurança**, porque ausente a legitimidade ativa *ad causam* do ora impetrante, que não mais ostenta a condição de membro de qualquer das Casas do Congresso Nacional” (**MS 27.971**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 1.º.07.2011, *DJE* de 1.º.08.2011).

Outro entendimento acarretaria a conversão do mandado de segurança, que não pode ser utilizado para a impugnação de normas em tese, em ADI, situação essa não admitida em nosso ordenamento jurídico.

E quais os limites do controle judicial?

Nos termos da jurisprudência do STF, o controle de constitucionalidade a ser exercido pelo Judiciário durante o processo legislativo abrange somente a garantia de um procedimento em total conformidade com a **Constituição, não lhe cabendo**, contudo, a extensão do controle sobre **aspectos discricionários concernentes às questões políticas e aos atos interna corporis**, vedando-se, desta feita, interpretações das normas regimentais (cf.: MS 22.503-3/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 06.06.1997, p. 24872, *Ement.* v. 01872-03, p. 385; j. 08.05.1996 — Tribunal Pleno, [52](#) descrevendo o posicionamento da Suprema Corte).

Os limites desse controle jurisdicional foram bem delimitados pela Corte no

julgamento do **MS 32.033** (Rel. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, j. 20.06.2013, Plenário, *DJE* de 18.02.2014), impetrado, preventivamente, por parlamentar, questionando projeto de lei que criava novas regras em relação à *transferência dos recursos do fundo partidário e ao horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão* nas hipóteses de migração partidária (*PL n. 4.470/2012* — aprovado pela Câmara e recebido no Senado Federal como *PLC n. 14/2013*, tendo sido transformado na *Lei n. 12.875/2013*).

De acordo com o voto do Min. Teori Zavascki, que abriu a divergência, contrário a uma posição mais elástica sustentada pelo Min. Gilmar Mendes (vencido), a Constituição admite o controle judicial preventivo, por meio de mandado de segurança a ser impetrado exclusivamente por parlamentar, em duas únicas hipóteses:

■ **PEC** manifestamente ofensiva a **cláusula pétrea** (MS 20.257/DF, Rel. Min. Moreira Alves — *leading case* — j. 08.10.1980);

projeto de lei ou *PEC* em cuja tramitação se verifique **manifesta ofensa** a cláusula constitucional que disciplinasse o correspondente **processo legislativo**.

Ou seja, em relação a **projeto de lei**, o STF restringiu o controle preventivo apenas para a hipótese de violação ao **devido processo legislativo**, não se admitindo a discussão sobre a matéria, buscando, assim, resguardar a **regularidade jurídico-constitucional do procedimento**, sob pena de se violar a **separação de poderes**.

Observem que essa delimitação de atuação do controle judicial se deu em relação ao **projeto de lei**, e não à **PEC** (proposta de emenda à Constituição). Isso porque o art. 60, § 4.º, veda a **proposta de emenda** tendente a abolir cláusula pétrea. Em nenhum momento a Constituição vedou a tramitação de *projeto de lei* que tenda a abolir cláusula pétrea. Ou seja, procurando ser mais claro: **a)** em relação a projeto de lei, o controle judicial não analisará a matéria, mas apenas o processo legislativo; **b)** em relação à PEC, o controle será mais amplo, abrangendo não apenas a regularidade de procedimento, mas, também, a matéria, permitindo o trancamento da tramitação de PEC que tenda a abolir

cláusula pétrea.

Com esse entendimento, a Corte **evitou** a **universalização** do controle preventivo e a necessidade de enfrentamento judicial **precoce** de questões políticas, que encontram um ambiente muito mais adequado de discussão, que é a Casa Legislativa.⁵³ Vejam que o questionamento sobre a matéria da lei (se o projeto de lei for transformado) poderá ser realizado em momento oportuno no controle concentrado a ser provocado pelos legitimados do art. 103.

Conforme estabeleceu o Min. Fux em seu voto, “essa aparente contradição entre os valores albergados pelo Estado Democrático de Direito impõe um dever de **cautela** redobrado no exercício da jurisdição constitucional. Com efeito, certo é que **os tribunais não podem asfixiar a autonomia pública dos cidadãos**, substituindo as escolhas políticas de seus representantes por preferências pessoais de magistrados não eleitos pelo povo, como, aliás, testemunhado pela história constitucional norte-americana durante a cognominada *Era da Lochner* (1905-1937), período em que a Suprema Corte daquele país freou a implantação do Estado social a partir de uma exegese inflacionada da cláusula aberta do devido processo legal (CHEMERINSKY, Erwin. *Constitutional law: principles and policies*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2011, p. 630-645)”.⁵⁴

E delimitou com precisão: “no caso vertente, não se sabe se o projeto de lei será arquivado, alterado ou aprovado. A questão deve permanecer em discussão, sob pena de um paternalismo judicial ou, para utilizar uma expressão bastante em voga, uma **supremocracia**. Na realidade, tutelar o direito dos parlamentares de oposição, diversamente do que abreviar a discussão, como pretende o Impetrante, é permitir que os debates sejam realizados de forma republicana, transparentes e com os canais de participação abertos a todos os que queiram deles participar. Esse sim é o modelo de atuação legislativa legítima, tal qual concebido por John Hart Ely” (fls. 19 de seu voto).

■ 6.4.1.4. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder judiciário e a perspectiva das “normas constitucionais interpostas” (Zagrebelsky)

O posicionamento acima exposto (MS 22.503), pela total não apreciação e interpretação de normas do Regimento Interno do Parlamento e que é a **regra (INCLUSIVE PARA SER ADOTADA NOS CONCURSOS PÚBLICOS)**, poderia ser visto com temperamentos quando se tratar de **normas constitucionais interpostas**.

A tese foi discutida pelo Min. Gilmar Mendes no MS 26.915, ⁵⁴ no qual se questionava a amplitude do art. 43 do RI da CD, que veda Deputado Federal relator de certa proposta de presidir a Comissão na qual será apreciada a matéria (*“Art. 43. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator. Parágrafo único. Não poderá o Autor de proposição ser dela Relator, ainda que substituto ou parcial”*).

Referido mandado de segurança impugnava a nomeação do Deputado Pedro Novais (PMDB/MA) para a presidência da Comissão especial que analisou a PEC n. 558/2006, a qual trata da prorrogação da CPMF, tendo em vista que ele seria um dos autores da proposição.

Em um primeiro momento (voto monocrático e em sede de medida cautelar), o Rel. Min. Gilmar Mendes analisou o Regimento Interno à luz do devido processo legislativo e, assim, entendeu que a regra fixada no art. 43 do RI da CD não se aplica aos projetos de Emenda Constitucional (PEC), indeferindo, portanto, o pedido de medida liminar, por estarem ausentes a *fumaça do bom direito* (plausibilidade jurídica) e o *perigo na demora da decisão*.

Mendes, trazendo em pauta o estudo de **Gustavo Zagrebelsky**, asseverou que “... se as normas constitucionais fizerem referência expressa a outras disposições normativas, a violação constitucional pode advir da violação dessas outras normas, que, muito embora não sejam formalmente constitucionais, vinculam os atos e procedimentos legislativos, constituindo-se **normas constitucionais interpostas** (ZAGREBELSKY, Gustavo. *La giustizia costituzionale*. Bologna, Mulino, 1979, p. 40-41). Na verdade, o órgão jurisdicional competente deve examinar a regularidade do processo legislativo, sempre tendo em vista a constatação de eventual afronta à Constituição

(CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional*, apud MENDES, Gilmar. *Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos*. Saraiva, 1990, p. 35-36), mormente, aos direitos fundamentais” (MS 26.915-MC/DF, 08.10.2007).

Assim, o tema ganha outro “colorido” à luz dessa nova perspectiva, devendo o conceito de matéria *interna corporis* ser temperado à luz da ideia das *normas constitucionais interpostas* que, segundo o Min. Gilmar Mendes, apresentariam uma força normativa diferenciada por derivar diretamente da Constituição **(tema pendente de julgamento e aprofundamento pelo STF, já que o referido MS foi extinto sem a apreciação da matéria)**. [55](#)

■ 6.4.2. Controle posterior ou repressivo

O controle posterior ou repressivo será realizado sobre a lei, e não mais sobre o projeto de lei, como ocorre no controle preventivo.

Vale dizer, os **órgãos de controle** verificarão se a lei, ou ato normativo, ou qualquer ato com indiscutível caráter normativo, possuem um **vício formal** (produzido durante o processo de sua formação), ou se possuem um vício em seu conteúdo, qual seja, um **vício material**. Mencionados órgãos variam de acordo com o sistema de controle adotado pelo Estado, podendo ser **político, jurisdicional**, ou **híbrido**.

■ 6.4.2.1. Controle político

Verifica-se em Estados onde o controle é exercido por um órgão distinto dos três Poderes, órgão esse garantidor da supremacia da Constituição. Tal sistema é comum em países da Europa, como Portugal e Espanha, sendo o controle normalmente realizado pelas **Cortes** ou **Tribunais Constitucionais**. [56](#)

Luís Roberto Barroso, como José Afonso da Silva, destaca o **modelo francês** estabelecido na Constituição de 1958 e que fixou um *Conselho Constitucional*, composto de 9 Conselheiros escolhidos pelo Presidente da República e pelo

Parlamento, tendo como membros natos os ex-Presidentes da República, como exemplo de **controle político**.

No Brasil, Barroso sustenta que o veto do Executivo a projeto de lei, por entendê-lo inconstitucional (veto jurídico), bem como a rejeição de projeto de lei na CCJ seriam exemplos de controle político. [57](#)

■ 6.4.2.2. *Controle jurisdicional*

O sistema de controle jurisdicional dos atos normativos é realizado pelo Poder Judiciário, tanto por um único órgão (**controle concentrado**) — no caso do direito brasileiro, pelo STF e pelo TJ — como por qualquer juiz ou tribunal (**controle difuso**), admitindo, naturalmente, o seu exercício por juízes em estágio probatório, ou seja, sem terem sido vitaliciados, bem como por juízes dos juizados especiais.

O Brasil adotou o sistema jurisdicional **misto**, porque realizado pelo Poder Judiciário — daí ser *jurisdicional* —, tanto de forma concentrada (controle concentrado) como por qualquer juiz ou tribunal (controle difuso). [58](#)

Importante anotar que os controles difuso e concentrado são realizados com autonomia, não podendo um condicionar a sua admissibilidade à inviolabilidade do outro. Claro que se já houver decisão no controle concentrado, mesmo em sede de medida cautelar, poderá haver repercussão sobre o controle difuso.

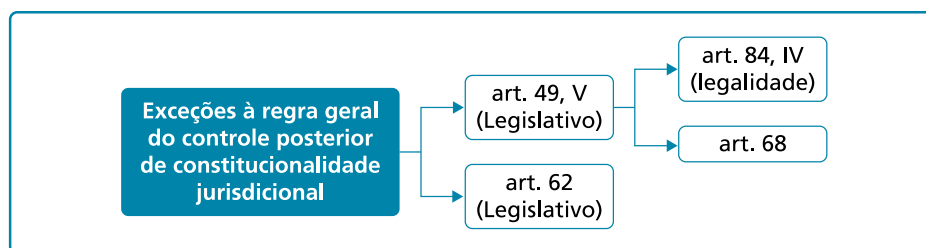
■ 6.4.2.3. *Controle híbrido*

No controle que chamamos de **híbrido**, temos uma *mistura* dos outros dois sistemas acima noticiados. Assim, algumas normas são levadas a controle perante um órgão distinto dos três Poderes (controle político), enquanto outras são apreciadas pelo poder judiciário (controle jurisdicional).

■ 6.4.2.4. *Exceção à regra geral do controle jurisdicional posterior ou repressivo*

Vimos que o controle posterior ou repressivo (sucessivo) no Brasil, por regra, é exercido pelo Poder Judiciário, de forma concentrada ou difusamente. A essa regra, no entanto, surgem exceções, fixando-se hipóteses de controle posterior ou repressivo pelo **Poder Legislativo** e pelo **Poder Executivo**.

■ 6.4.2.4.1. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Legislativo



A **primeira exceção** à regra geral do controle posterior jurisdicional misto (difuso e concentrado) vem prevista no **art. 49, V**, da CF/88, que estabelece ser competência exclusiva do Congresso Nacional *sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa*. Mencionado controle será realizado através de **decreto legislativo** a ser expedido pelo Congresso Nacional. Vamos às hipóteses:

a) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar: como veremos melhor ao tratar do Poder Executivo, é de competência exclusiva do Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 84, IV). Portanto, ao Chefe do Executivo compete regulamentar uma lei expedida pelo Legislativo, e tal procedimento será feito por decreto presidencial. Pois bem, se no momento de regulamentar a lei o Chefe do Executivo extrapolá-la, disciplinando além do limite nela definido, este “a mais” poderá ser afastado pelo Legislativo por meio de decreto legislativo. Cabe alertar que, no fundo, esse controle é de **legalidade** e não de inconstitucionalidade, como apontado por parte da doutrina, pois o que se verifica é em que medida o decreto regulamentar extrapolou os limites da **lei**;

b) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem dos

limites de delegação legislativa: como veremos ao estudar as espécies normativas, a Constituição atribuiu competência ao Presidente da República para elaborar a **lei delegada**, mediante delegação do Congresso Nacional, através de **resolução**, especificando o conteúdo e os termos de seu exercício (art. 68). Pois bem, no caso de elaboração de lei delegada pelo Presidente da República, extrapolando os limites da aludida resolução, poderá o Congresso Nacional, utilizando-se de **decreto legislativo**, sustar o referido ato que exorbitou dos limites da delegação legislativa.

A **segunda exceção** à regra geral está prevista no **art. 62** da CF/88. Conforme estudaremos adiante, em caso de **relevância** e **urgência**, o Presidente da República poderá adotar **medidas provisórias**, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao **Congresso Nacional** (Poder Legislativo). Entendendo-a **inconstitucional** (vejam: as medidas provisórias têm força de lei), o Congresso Nacional estará realizando controle de constitucionalidade. Trata-se de exceção à regra geral, haja vista que, nessa hipótese, o controle não é exercido pelo Judiciário (lembrem: o Brasil adotou o **sistema de controle jurisdicional misto**), mas sim pelo Legislativo.

■ 6.4.2.4.2. *Controle posterior ou repressivo exercido pelo Executivo*

Como se sabe, o **princípio da supremacia da Constituição** produz **efeitos irradiantes** em todos os Poderes da República, os quais, por sua vez, devem cumprir as leis que se coadunem com a Constituição.

O grande problema surge quando a lei é inconstitucional. Devem os Poderes necessariamente aplicá-la, ou podem, sem qualquer formalidade, deixar de cumpri-la sob o fundamento de violação da Constituição?

Entendimento antes do advento da CF/88: como vimos, o controle concentrado surge somente com a EC n. 16/65, que estabelece, como exclusivo legitimado, o PGR. Assim, antes do texto de 1988, que ampliou a legitimação ativa para o ajuizamento da ADI, os Chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores dos Estados e do DF e Prefeitos)

não tinham competência para ajuizar ação buscando, em controle concentrado, discutir a constitucionalidade da lei.

Nesse primeiro momento, portanto, doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que o Chefe do Executivo poderia deixar de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional, cabendo-lhe, ainda, baixar determinação, na condição de **superior hierárquico**, para que os seus subordinados também não cumprissem a lei.

Isso porque a análise da constitucionalidade da lei não era tida como monopólio do Judiciário, embora tivesse o seu controle final (Caio Tácito, *RDA* 59/339 e s.).

Naturalmente a ação ou omissão do Poder Executivo poderia ser discutida no Judiciário, que daria a “palavra final” sobre a aplicação ou não da lei (como se sabe, o Judiciário é o intérprete final da lei), obrigando, após a decisão, à necessária observância do dispositivo legal. [59](#)

Entendimento a partir do advento da CF/88: já vimos que o argumento para justificar a possibilidade de descumprimento da lei pelo Executivo fundava-se no fato de a legitimação para o controle concentrado de constitucionalidade das leis ser **exclusiva** do PGR.

Assim, aparentemente, com o advento da CF/88, que ampliou a legitimação para o ajuizamento da ADI (art. 103, expandida para a ADC pela EC n. 45/2004), não mais se admitiria o descumprimento de lei inconstitucional pelo Chefe do Executivo.

A tese ganhou alguns adeptos na doutrina. [60](#) Outros, porém, alertaram para uma realidade: de fato, pela nova regra, são legitimados o **Presidente da República** (art. 103, I) e os **Governadores dos Estados e do DF** (art. 103, V). E quanto aos **Prefeitos**?

Estes não estão previstos no rol de legitimados do art. 103. Então alguns sustentavam que poderiam os Prefeitos, e somente eles, descumprir a lei flagrantemente inconstitucional, determinando a sua não aplicação para os subordinados hierárquicos.

Essa tese, contudo, mostrou-se bastante complicada, pois, em certa medida, acarretava maior atribuição de poderes aos Chefes dos Executivos municipais em detrimento dos estaduais e em relação ao Presidente da República.

Em virtude dessa situação, buscou a doutrina outra justificativa, que não a meramente formal, para a configuração da tese do descumprimento da lei e, assim, manter a regra que prevalecia antes do texto de 1988: princípio da **supremacia da Constituição** e da regra de que a aplicação de lei inconstitucional é o mesmo que a negativa de aplicação da própria Constituição.⁶¹

Entendemos que a **tese** a ser adotada é a da **possibilidade de descumprimento da lei inconstitucional pelo Chefe do Executivo**.

Isso porque entre os efeitos do controle concentrado está a **vinculação** dos demais órgãos do Poder Judiciário e do **Executivo** (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 e art. 102, § 2.º, da CF/88 — EC n. 45/2004).

Outro argumento a fortalecer a ideia da possibilidade de descumprimento da lei flagrantemente inconstitucional pelo Executivo decorre dos efeitos da **súmula vinculante** (*Reforma do Judiciário*), que, uma vez editada, vinculará a Administração Pública, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal (art. 64-B da Lei n. 9.784/99, introduzido pela Lei n. 11.417/2006).

Antes, porém, *a contrario sensu* e desde que não exista qualquer medida judicial em sentido contrário, tecnicamente, poderá o Chefe do Executivo determinar a não aplicação de lei flagrantemente inconstitucional.

E qual a posição do STF e do STJ sobre o tema?

Encontramos apenas um precedente no **STF**, que não aprofunda muito o assunto: “... O controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e Legislativo, por sua chefia — e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade —, **podem tão só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem**

inconstitucionais” (ADI 221-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves; *DJ* de 22.10.1993, p. 22251, *Ement.* v. 01722-01, p. 28 — grifamos).

A 1.^a Turma do **STJ**, por sua vez, já enfrentou o tema com maior veemência, **consagrando a tese do controle posterior ou repressivo pelo Executivo**: “Lei inconstitucional — Poder Executivo — Negativa de eficácia. O poder executivo deve negar execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional” (**REsp 23121/GO**, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; 1.^a Turma, j. 06.10.1993, *DJ* de 08.11.1993, p. 23521, *LEXSTJ* 55/152).

■ 6.4.2.4.3. **Controle posterior ou repressivo exercido pelo TCU**

O **TCU** (cf. *item 9.15*), dentre outras competências previstas no art. 71 da CF/88, auxilia o Congresso Nacional no controle externo.

Daí, ao exercer as suas atividades poderá, sempre no caso concreto e de modo incidental, apreciar a constitucionalidade de uma lei e, se for o caso, deixar de aplicá-la.

Nesse sentido, destacamos a **S. 347/STF**: “o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”.⁶²

Conforme anota Bulos, embora os Tribunais de Contas “... não detenham competência para declarar a inconstitucionalidade das leis ou dos atos normativos em abstrato, pois essa prerrogativa é do Supremo Tribunal Federal, poderão, no caso concreto, reconhecer a desconformidade formal ou material de normas jurídicas, incompatíveis com a manifestação constituinte originária. Sendo assim, os Tribunais de Contas podem deixar de aplicar ato por considerá-lo inconstitucional, bem como sustar outros atos praticados com base em leis vulneradoras da Constituição (art. 71, X). Reitere-se que essa faculdade é na via incidental, no caso concreto, portanto”.⁶³

Devemos alertar que a subsistência da S. 347 está em discussão⁶⁴ no STF e vem sendo criticada a partir de decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, em 22.03.2006, ao deferir pedido de medida liminar no **MS 25.888** impetrado pela

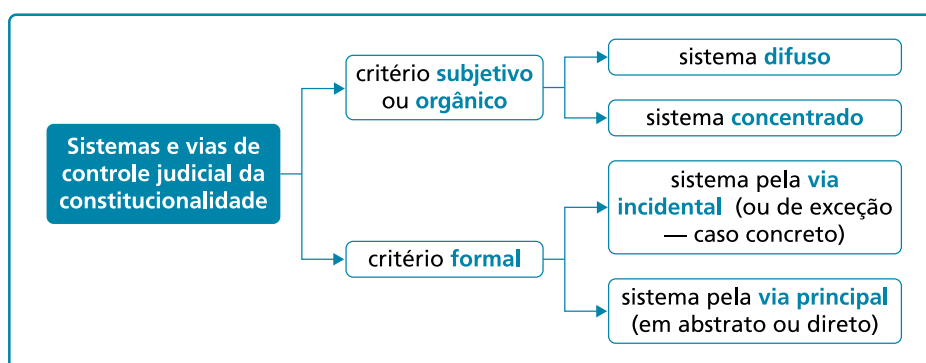
PETROBRAS, atacando ato do TCU que determinou à impetrante e seus gestores que se abstenham de aplicar o *Regulamento de Procedimento Licitatório Simplificado*, aprovado pelo Dec. n. 2.745/98, devendo ser observadas as regras da Lei n. 8.666/93.

Segundo fundamenta o Min. Gilmar Mendes, inclusive em sede doutrinária, a S. 347 foi editada em 13.12.1963, na vigência da Constituição de 1946 e quando ainda não existia qualquer forma de controle concentrado no Brasil. Lembre-se de que, naquele momento, vigorava apenas o controle difuso, já que a introdução do controle concentrado se deu pela EC n. 16/65, que estabeleceu um exclusivo legitimado, qual seja, o PGR.

Naquele contexto, argumenta, admitia-se a não aplicação da lei considerada inconstitucional. Contudo, com o advento da CF/88 e a alteração radical na legitimação ativa para a propositura da ADI genérica (art. 103), não mais se justifica o entendimento firmado na S. 347.

Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, “a própria **evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil**, verificada desde então, **está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da Súmula 347** em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988” (*pendente de análise pelo Pleno*).

■ 6.5. SISTEMAS E VIAS DE CONTROLE JUDICIAL



Assim, como se percebe pelo quadro acima, partindo de um critério **subjetivo** ou **orgânico**, o controle judicial de constitucionalidade poderá ser **difuso** ou

concentrado.

O sistema **difuso** de controle significa a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência, realizar o controle de constitucionalidade.

Por seu turno, no sistema **concentrado**, como o nome já diz, o controle se “concentra” em um ou mais de um (porém em número limitado) órgão. Trata-se de **competência originária** do referido órgão.

Sob outra perspectiva, do ponto de vista **formal**, o sistema poderá ser pela **via incidental** ou pela **via principal**.

No sistema de controle pela **via incidental** (também chamado pela via de exceção ou defesa), o controle será exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal.

Nesse ponto, é conveniente fazer uma crítica ao uso da terminologia “pela via de exceção ou defesa”, na medida em que será possível que a via incidental (análise de questão prejudicial) se dê, também, como fundamento da pretensão do autor, o que se vê nas ações constitucionais, a exemplo do mandado de segurança.

Já no sistema de controle pela **via principal** (abstrata ou pela via de “ação”), a análise da constitucionalidade da lei será o objeto principal, autônomo e exclusivo da causa.

Mesclando as duas classificações, verifica-se que, regra geral, o sistema **difuso** é exercido pela via **incidental**, destacando-se, aqui, a experiência norte-americana, que, inclusive, influenciou o surgimento do controle difuso no Brasil.

Por sua vez, o sistema **concentrado** é exercido pela via **principal**, como decorre da experiência austríaca e se verifica no sistema brasileiro.

Essa regra, contudo, apresenta **exceções**, tanto no *direito estrangeiro* como no *direito brasileiro*.

Conforme anota Barbosa Moreira ao tratar sobre o **direito estrangeiro** “características ecléticas apresentam os sistemas atuais de controle na **Itália** e na **República Federal da Alemanha**, que reconhecem a um único órgão judicial competência para apreciar a questão da constitucionalidade, mas lhe deferem o

exercício dessa competência quer pela via *principal* (mediante provocação de algum legitimado), quer por via *incidental*, a propósito de caso concreto, sujeito à cognição de qualquer outro órgão judicial, que submete a questão à Corte Constitucional, a fim de que esta a resolva com força vinculativa, ficando suspenso, nesse meio-tempo, o processo em que se suscitou a questão. Na mesma corrente insere-se a Constituição espanhola de 1978 (arts. 161 a 165)”.⁶⁵

No **direito brasileiro**, como exceção à regra do controle **concentrado e abstrato de constitucionalidade**, podemos pensar em situação na qual o controle será **concentrado** (em órgão de cúpula, com competência originária), mas **incidental**, discutindo-se a questão de constitucionalidade como questão prejudicial ao objeto principal da lide.

Como exemplo de controle concentrado e incidental, então, citamos o art. 102, I, “d”, que estabelece ser **competência originária do STF** processar e julgar o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.

■ 6.6. CONTROLE DIFUSO

■ 6.6.1. Origem histórica: Marbury *versus* Madison, Sessão de fev. de 1803 (I, repertório de Cranch, 137-180)

CONTROLE DIFUSO — HISTÓRICO		
■ John Adams (Presidente EUA)		■ Thomas Jefferson (novo Presidente EUA)

■ William Marbury — nomeado “juiz de paz” (juiz federal) — mas a “comissão” para o cargo, embora assinada, não lhe foi entregue	X	■ James Madison — nomeado Secretário de Estado — não efetivou a “comissão” por ordem de Jefferson
■ John Marshall, Chief Justice ■ A lei (seção 13 do Judiciary Act, de 1789) x a Constituição de 1787, que não fixou competência originária para apreciar a questão ■ Solução: Havendo conflito entre a aplicação de uma lei e a Constituição, aplica-se a regra constitucional, por ser hierarquicamente superior		

John Adams, presidente dos EUA, foi derrotado na eleição presidencial por Thomas Jefferson.

Adams resolveu, antes de ser sucedido por Jefferson, nomear diversas pessoas ligadas ao seu governo como juizes federais, destacando-se William Marbury, cuja “comissão” para o cargo de “juiz de paz” do condado de Washington foi assinada por Adams, sem, contudo, ter-lhe sido entregue.

Jefferson, por sua vez, ao assumir o governo, nomeou James Madison como seu Secretário de Estado e, ao mesmo tempo, por entender que a nomeação de Marbury era incompleta até o ato da “comissão”, já que esta ainda não lhe havia sido entregue, determinou que Madison não mais efetivasse a nomeação de Marbury.

Naturalmente, Marbury acionou Madison pedindo explicações. Sem resposta, Marbury resolveu impetrar *writ of mandamus*, buscando efetivar a sua nomeação.

Depois de dois longos anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América resolveu enfrentar a matéria. John Marshall, *Chief Justice*, em seu voto, analisou vários pontos, dentre os quais a questão de se a Suprema Corte teria competência para apreciar ou não aquele remédio de *writ of mandamus*.

Isso porque, segundo a Constituição dos EUA, “o Supremo Tribunal terá jurisdição originária em todas as causas concernentes a embaixadores, outros ministros públicos e cônsules, e nos litígios em que for parte um Estado. Em todas as outras causas, o Supremo Tribunal terá jurisdição em grau de recurso”.[66](#)

Ou seja, na prática, pela primeira vez teria a Suprema Corte de analisar se deveria prevalecer a lei (seção 13 do *Judiciary Act*, de 1789, que determinava a apreciação da matéria pela Suprema Corte) ou a Constituição de 1787, que não fixou tal competência originária, em verdadeiro conflito de normas.

Até então, a regra era a de que a lei posterior revogava a lei anterior. Assim, teria a lei revogado o artigo de Constituição que tratava das regras sobre competência originária?

Depois de muito meditar, inclusive sobre o papel da Constituição escrita, Marshall conclui: “assim, a ‘fraseologia’ particular da Constituição dos Estados Unidos confirma e corrobora o princípio essencial a todas as constituições escritas, segundo o qual é **nula** qualquer lei incompatível com a Constituição; e que os tribunais, bem como os demais departamentos, são vinculados por esse instrumento”.[67](#)

Pode-se, assim, afirmar que a noção e ideia de controle difuso de constitucionalidade, historicamente, deve-se ao famoso caso julgado pelo Juiz *John Marshall* da Suprema Corte norte-americana, que, apreciando o caso **Marbury v. Madison**, em 1803, decidiu que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei em um caso concreto e a Constituição, deve prevalecer a Constituição, por ser hierarquicamente superior.

Como anota Oscar Vilhena, o precedente *Marbury v. Madison* “... é resultado, única e exclusivamente, de uma leitura expandida da Constituição americana e, posteriormente, na tradição da *common law*, da ação reiterada dos magistrados. Este poder de controlar a compatibilidade das leis com a Constituição decorre, assim, da jurisprudência americana, e não de uma autorização positivada de forma expressa pelo constituinte”.[68](#)

■ 6.6.2. Noções gerais

O **controle difuso**, repressivo, ou posterior, é também chamado de controle pela via de **exceção** ou **defesa**, ou controle **aberto**, sendo realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário. Quando dizemos qualquer juízo ou tribunal, devem ser observadas, é claro, as regras de competência processual, a serem estudadas no processo civil.

O controle difuso verifica-se em um caso concreto, e a declaração de inconstitucionalidade dá-se de forma incidental (*incidenter tantum*), prejudicialmente ao exame do mérito.

Pede-se algo ao juízo, fundamentando-se na inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ou seja, a alegação de inconstitucionalidade será a *causa de pedir processual*.

Exemplo: na época do Presidente Collor, os interessados pediam o desbloqueio dos cruzados fundando-se no argumento de que o ato que motivou tal bloqueio era inconstitucional. O pedido principal não era a declaração de inconstitucionalidade, mas sim o desbloqueio!

■ 6.6.3. Controle difuso nos tribunais e a cláusula de reserva de plenário (*full bench*). Art. 97 da CF/88

■ 6.6.3.1. Regras gerais

Observadas as regras do processo civil, a parte sucumbente poderá devolver a análise da matéria ao tribunal *ad quem* (nessa hipótese estamos imaginando um processo que começou na primeira instância — juízo monocrático, sendo interposto recurso de apelação para o tribunal competente).

No tribunal competente, distribuído o processo para uma turma, câmara ou seção (depende da organização interna do tribunal a ser estabelecida em seu regimento interno), verificando-se que existe questionamento incidental sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo, suscita-se uma **questão de ordem** e

a análise da constitucionalidade da lei é remetida ao **pleno**, ou **órgão especial** do tribunal, para resolver aquela questão suscitada.

Nesse sentido é que o **art. 97 da CF/88** estabelece que somente pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a **inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo do Poder Público.⁶⁹ Temos aqui a chamada **cláusula de reserva de plenário**, também denominada regra do *full bench*.

Questão interessante diz respeito à interpretação do referido art. 97 da CF, no sentido de ser ou não sempre necessária a apreciação pelo órgão especial ou pleno da **questão prejudicial**, qual seja, a realização do controle *incidenter tantum* de constitucionalidade da lei ou ato normativo pelos aludidos órgãos.

Assevera Marcelo Caetano, citado pelo Ministro Celso de Mello (RE 190.725-8/PR), que “... a exigência de maioria qualificada para a declaração da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo justifica-se pela preocupação de só permitir ao Poder Judiciário tal declaração quando o vício seja manifesto e, portanto, salte aos olhos de um grande número de julgadores experientes caso o órgão seja colegiado. Sendo atingida a majestade da lei a qual, em princípio, se beneficia da presunção de estar de acordo com a Constituição, é necessário que o julgamento resulte de um consenso apreciável e não brote de qualquer escassa maioria (...). Essa exigência, por outro lado, acautela contra uma futura variação de jurisprudência no mesmo Tribunal. Assim, a inconstitucionalidade tem de ser declarada pelos votos conformes de um número de juízes equivalente a metade e mais um dos membros do Tribunal ou do órgão competente nele formado”.⁷⁰ e ⁷¹

A regra do art. 97 destaca-se como verdadeira **condição de eficácia jurídica da própria declaração de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público**.⁷² Nesse sentido, destacamos a **Súmula Vinculante 10/STF**:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

No entanto, enaltecendo o **princípio da economia processual, da segurança jurídica** e na busca da desejada **racionalização orgânica da instituição judiciária brasileira**, vem-se percebendo a inclinação para a dispensa do procedimento do art. 97 toda vez que já haja decisão do órgão especial ou pleno do tribunal, ou do STF, o guardião da Constituição sobre a matéria.

Segundo o Ministro Ilmar Galvão, “declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, pela maioria absoluta dos membros de certo Tribunal, soaria como verdadeiro despropósito, notadamente nos tempos atuais, quando se verifica, de maneira inusitada, a repetência desmesurada de causas versantes da mesma questão jurídica, vinculadas à interpretação da mesma norma, que, se exigisse, em cada recurso apreciado, a renovação da instância incidental da arguição de inconstitucionalidade, levando as sessões da Corte a uma monótona e interminável repetição de julgados da mesma natureza” (RE 190.725-8/PR). [73](#)

Essa tendência foi confirmada pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998, que, acrescentando um parágrafo único ao art. 481 do CPC/73 (art. 949, parágrafo único, do CPC/2015), estabeleceu: “os órgãos fracionários dos tribunais (entenda-se Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções) não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamentos destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”, podendo, inclusive, referida ação ser, de plano, apreciada, conhecida e julgada pelo relator, na redação dada ao art. 557 e acréscimo de um § 1.º-A ao CPC/73 pelo mesmo dispositivo legal (art. 932, IV, “a”, e V, “a”, CPC/2015). [74](#)

A **mitigação da cláusula de reserva de plenário** vem sendo observada em outras situações. Conveniente, portanto, esquematizar a matéria. Assim, não há a necessidade de se observar a regra do art. 97, CF/88:

na citada hipótese do **art. 481 do CPC/73**, acima (art. 949, parágrafo único, CPC/2015);

se Tribunal **mantiver a constitucionalidade do ato normativo**, ou seja, não afastar a sua presunção de validade (o art. 97 determina a observância

do *full bench* para declarar a *inconstitucionalidade* de lei ou ato normativo do Poder Público);

nos casos de **normas pré-constitucionais**, porque a análise do direito editado no ordenamento jurídico anterior em relação à nova Constituição não se funda na teoria da inconstitucionalidade, mas, como já estudado, em sua recepção ou revogação;⁷⁵

quando o Tribunal utilizar a técnica da **interpretação conforme a Constituição**, pois não haverá declaração de inconstitucionalidade;⁷⁶

nas hipóteses de decisão em sede de **medida cautelar**, já que não se trata de decisão definitiva.⁷⁷

■ 6.6.3.2. A cláusula de reserva de plenário se aplica às Turmas do STF no julgamento de RE?

De acordo com o art. 9.º, III, do *RISTF*, é **competência das Turmas** (1.ª ou 2.ª) o julgamento de **recurso extraordinário**, que será distribuído a um Ministro e ficará atrelado à Turma em relação a qual o Ministro integra, ressalvadas as hipóteses regimentais de prevenção.

Apesar dessa regra geral, consoante o art. 11, I, do *RISTF*, a **Turma** remeterá o feito ao julgamento do Plenário independente de acórdão e de nova pauta:

quando considerar **relevante a arguição de inconstitucionalidade** ainda não decidida pelo Plenário, e o Relator não lhe houver afetado o julgamento;

quando, não obstante decidida pelo Plenário a questão de inconstitucionalidade, algum Ministro **propuser** o seu **reexame**;

quando algum Ministro propuser **revisão da jurisprudência** compendiada na Súmula.

Ainda, o art. 22 do *RISTF* permite que o Relator **afete** a questão ao **Plenário** quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida, notadamente:

quando houver matérias em que **divirjam** as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário;

quando em razão da **relevância da questão jurídica** ou da necessidade de **prevenir divergência entre as Turmas** convier pronunciamento do Plenário.

Portanto, tendo como premissa que o julgamento do RE é de competência da Turma no STF, o encaminhamento do RE ao Plenário **depende** do preenchimento das hipóteses regimentais, e não, simplesmente, de requerimento da parte.

Dessa forma, de acordo com as **normas regimentais** — e apresentaremos crítica em seguida —, **a cláusula de reserva de plenário não se aplica às Turmas do STF no julgamento do RE**, seja por não se tratar de “tribunal” no sentido fixado no art. 97 (e essa poderia ser uma justificção para não ficarmos apenas com o fundamento regimental, apesar de não concordarmos), seja, tendo em vista ser função primordial e essencial da Corte a declaração de inconstitucionalidade, a possibilidade de afetação dessa atribuição aos seus órgãos fracionários, no caso, as Turmas.

Na atualidade, inclusive, observa-se, até dentro da ideia de *efetividade do processo e racionalização*, cada vez mais, a **ampliação da competência das Turmas** (*vide*, por exemplo, as *Emendas Regimentais ns. 45/2011 e 49/2014*), tornando, assim, mais ágeis as decisões do Plenário, cujas sessões são realizadas apenas às quartas e quintas-feiras da semana.

Nesse sentido, destacamos **controvertido** precedente da 2.^a T. do STF que, inclusive, já foi cobrado na prova do *MPF/2011*. Vejamos:

“O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, **tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da CF**” (RE **361.829-ED**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02.03.2010, 2.^a Turma, *DJE* de 19.03.2010).[78](#)

CRÍTICA: com o máximo respeito, entendemos esse posicionamento não adequado e **violador** da regra do art. 97 da CF/88, que se mostra extremamente clara e didática:

“**Art. 97.** Somente pelo voto da maioria absoluta de **seus membros** ou dos

membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Ou seja, a atribuição foi expressamente fixada para o Plenário ou para o órgão especial, e não para a Turma. Como o STF não tem órgão especial, a atribuição, então, seria do **Pleno**. Portanto, a regra regimental não se adapta à fixada no art. 97. Eventual outro entendimento dependeria de **reforma constitucional**, não sendo suficiente mera alteração regimental.

Propondo **interpretação intermediária**, o **Min. Roberto Barroso** apresenta a seguinte orientação: “a **cláusula da reserva de plenário não é exigida** quando o Supremo Tribunal Federal, na sua **competência recursal, mantém acórdão recorrido** que declarou a inconstitucionalidade de norma local em processo de controle por ação direta estadual. Nesses casos, assenta-se tão somente a conformidade do *decisum* recorrido com o entendimento desta Corte, órgão incumbido do papel de intérprete máximo da Constituição. **Hipótese diversa** é aquela em que, afastada a inconstitucionalidade pelo Tribunal de origem, esta Corte **dá provimento ao recurso extraordinário para extinguir do ordenamento jurídico a norma impugnada**. Em tais condições, em observância ao disposto no art. 97 da Constituição Federal, deve ser o julgamento do feito **afetado** ao Plenário desta Corte” (ARE 661.288, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.05.2014, 1.^a T., *DJE* de 29.09.2014, fls. 27 do acórdão). Vamos aguardar manifestação plenária sobre o assunto (**pendente**).

O tema, certamente, precisará ser **rediscutido** pelo Plenário do STF, especialmente diante da nova composição, esperando que a Corte retome a exigibilidade de observância ao art. 97, CF/88.

■ 6.6.3.3. **A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais?**

Não.

Isso porque, embora órgão recursal, as Turmas de Juizados não são consideradas **“tribunais”**.

O art. 97 da CF/88 refere-se aos tribunais indicados no art. 92 e respectivos órgãos especiais mencionados no art. 93, XI. As **Turmas dos Juizados**, no âmbito recursal, **não funcionam sob o regime de plenário ou de órgão especial** (ARE 792.562-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.03.2014, 2.^a T., DJE de 02.04.2014).

Dessa forma, as Turmas Recursais, órgãos colegiados dos Juizados, poderão declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei ou afastar a sua incidência no todo ou em parte sem que isso signifique violação ao art. 97 da CF/88 e à SV 10/STF.

Isso não impede, contudo, que a parte sucumbente interponha recurso extraordinário contra a decisão da Turma Recursal, para o STF apreciar a questão constitucional (S. 640/STF).

Apenas se faz o alerta de que, conforme já decidiu o STF, embora a cláusula de reserva de plenário não se aplique às Turmas Recursais de Juizados, isso não significa que os requisitos de admissibilidade inerentes ao cabimento do RE (art. 102, III, da CF/88) poderão ser desrespeitados. Assim, indispensável a **juntada do inteiro teor da decisão que tenha declarado a inconstitucionalidade e que será objeto do recurso extraordinário**. Nesse sentido:

“EMENTA: A regra da chamada **reserva do plenário** para declaração de inconstitucionalidade (art. 97 da CF) **não se aplica**, deveras, **às turmas recursais de Juizado Especial**. Mas tal circunstância em nada atenua nem desnatura a **rigorosa exigência de juntada de cópia integral do precedente que tenha, ali, pronunciado inconstitucionalidade de norma objeto de recurso extraordinário fundado no art. 102, III, ‘b’, da Constituição da República**, pela mesmíssima razão por que, a igual título de admissibilidade do recurso, não se dispensa juntada de cópia de acórdão oriundo de plenário” (**RE 453.744-AgR**, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.06.2006, 1.^a Turma, DJ de 25.08.2006. No mesmo sentido: RE 529.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.05.2011. Ainda, AI 561.181-AgR, RE 369.696-AgR, AI 431.863-AgR, RE 466.834).

■ 6.6.3.4. A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão de juízo monocrático de primeira instância?

Não.

Como visto, a regra do art. 97 é estabelecida para “tribunal”, não estando, portanto, direcionada para o juízo monocrático, mesmo que, incidentalmente, no controle difuso, declare a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Vejamos as lições do Min. Celso de Mello:

“EMENTA: A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Política, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a **competência funcional** por objeto do juízo para proferir decisões declaratórias de inconstitucionalidade. Órgãos fracionários dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispõem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies jurídicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. **A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal**, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, **não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional** (RT 554/253)” (**HC 69.921**, voto do Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.02.1993, 1.^a Turma, *DJ* de 26.03.1993).

■ 6.6.4. Efeitos da decisão

■ 6.6.4.1. Para as partes

Regra geral, os efeitos de qualquer sentença valem somente para as partes que litigaram em juízo, não extrapolando os limites estabelecidos na lide.

No momento que a sentença declara ser a lei inconstitucional (controle difuso realizado incidentalmente), produz efeitos pretéritos, atingindo a lei desde a sua edição, tornando-a **nula** de pleno direito. Produz, portanto, **efeitos retroativos**.

Assim, no controle difuso, para as partes os efeitos serão: *a) inter partes* e *b) ex tunc*.

Cabe alertar que o STF já entendeu que, mesmo no controle difuso, poder-se-á dar efeito *ex nunc* ou *pro futuro*.

O *leading case* foi o julgamento do **RE 197.917**, pelo qual o STF reduziu o número de vereadores do Município de Mira Estrela de 11 para 9 e determinou que a aludida decisão só atingisse a próxima legislatura (cf. íntegra do voto em *Inf. 341/STF*, Rel. Min. Maurício Corrêa).

O Ministro Gilmar Mendes, em outra oportunidade, desenvolveu com maestria o entendimento fixado no caso de Mira Estrela, ao julgar a Ação Cautelar n. 189: “segundo o ministro, trata-se de questão idêntica à discutida no Recurso Extraordinário 197.917, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, em que o Plenário decidiu pela inconstitucionalidade de Lei Orgânica municipal, que estabelecia o número de vereadores, determinando, porém, a eficácia dos efeitos para momento futuro. ‘Como se pode ver, se se entende inconstitucional a lei municipal em apreço, impõe-se que se limitem os efeitos dessa declaração (*pro futuro*)’, afirmou Mendes. O ministro ressaltou que o sistema difuso ou incidental de controle de constitucionalidade admite a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e, em casos determinados, acolheu até mesmo a pura declaração de inconstitucionalidade com efeito exclusivamente *pro futuro*. Para Gilmar Mendes, no caso em tela, observa-se que eventual declaração de inconstitucionalidade com efeito *ex tunc* (retroativo) ocasionaria repercussões em todo o sistema atual, atingindo decisões tomadas em momento anterior à eleição, que resultou na atual composição da Câmara Municipal: fixação do número de vereadores, fixação do número de candidatos, definição do quociente eleitoral. Igualmente, as decisões tomadas posteriormente ao pleito eleitoral também seriam atingidas, tal como a validade da deliberação da Câmara municipal nos diversos projetos e leis aprovados. O ministro ressaltou que a

doutrina e jurisprudência entendem que a margem de escolha conferida ao Tribunal para a fixação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade não legitima a adoção de decisões arbitrárias, estando condicionada pelo princípio de proporcionalidade” (cf. *Notícias STF*, 06.04.2004 — 20h17).

Por fim, em relação ao efeito *inter partes*, será que não haveria algum instrumento por meio do qual seria possível estender os efeitos de uma única decisão para todas as pessoas que estiverem em igual situação, evitando, assim, a necessidade de cada uma provocar o Judiciário individualmente? Isso é esperado em ações cujo objeto seja comum a um número muito grande de pessoas, como os *cruzados bloqueados*, a **cobrança de um tributo que entendam inconstitucional**, por exemplo, a extinta CPMF etc. Existiria, então, algum meio de se produzirem efeitos para todos, ou, necessariamente, cada indivíduo, isoladamente, deverá “bater às portas” do judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida? Sim, existe um mecanismo. Passemos a estudá-lo (art. 52, X). Em seguida, destacaremos uma nova tendência em razão daquilo que vem sendo chamado de **transcendência dos motivos determinantes da sentença** em controle difuso (perspectiva nova e já enfrentada pelo STF — RCL 4.335, j. 20.03.2014, *DJE* de 21.10.2014), ou de **abstrativização do controle difuso**, ou de **objetivação** do controle difuso.

■ 6.6.4.2. Para terceiros (art. 52, X)

■ 6.6.4.2.1. Procedimento

Vimos anteriormente que, através da interposição de *recurso extraordinário*, nas hipóteses constitucionalmente previstas, a questão poderá ser levada à apreciação do STF, que, também, realizará o controle difuso de constitucionalidade, de forma incidental.

Declarada inconstitucional a lei pelo STF, no controle difuso, desde que tal decisão seja definitiva e deliberada pela **maioria absoluta** do pleno do tribunal (art. 97 da CF/88),⁷⁹ o art. 178 do Regimento Interno do STF (*RISTF*)

estabelece que será feita a comunicação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do trânsito em julgado, ao **Senado Federal**, para os efeitos do art. 52, X, da CF/88.

O art. 52, X, da CF/88, por sua vez, estabelece ser competência privativa do Senado Federal, mediante o instrumento da **resolução**, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.

Regulamentando o assunto, o art. 386 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece que o Senado conhecerá da declaração, proferida em decisão definitiva pelo STF, de inconstitucionalidade, total ou parcial, de lei mediante: *a*) comunicação do Presidente do Tribunal; *b*) representação do Procurador-Geral da República; *c*) projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A comunicação, a representação e o projeto a que se refere o artigo anterior deverão ser instruídos com o **texto da lei cuja execução se deva suspender, do acórdão do Supremo Tribunal Federal, do parecer do Procurador-Geral da República** e da **versão do registro taquigráfico do julgamento**, isso tudo conforme o art. 387 do Regimento Interno do Senado.

E o art. 388 conclui o procedimento determinando que, após a leitura em plenário, a comunicação ou representação será encaminhada à **Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania**, que formulará projeto de **resolução** suspendendo a execução da lei, no todo ou em parte (CF, art. 52, X).

■ 6.6.4.2.2. *Amplitude do art. 52, X*

A suspensão pelo Senado Federal poderá dar-se em relação a leis **federais, estaduais, distritais** ou mesmo **municipais** que forem declaradas inconstitucionais pelo STF, de modo incidental, no controle difuso de constitucionalidade. [80](#)

Em se tratando de lei municipal ou lei estadual confrontadas perante a **Constituição Estadual**, Michel Temer entende que, em face do princípio

federativo, “pode e deve o Tribunal de Justiça ou Tribunal de Alçada,[81](#) após declarar a inconstitucionalidade, remeter essa declaração à Assembleia Legislativa para que esta suspenda a execução da lei (evidentemente, nos Estados em que as Constituições confirmam essa competência à Assembleia)”.[82](#)

■ 6.6.4.2.3. A expressão “no todo ou em parte”

Como visto, nos termos do art. 52, X, compete ao Senado Federal, por meio de **resolução**, suspender a execução, **no todo ou em parte**, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A expressão “no todo ou em parte” deve ser interpretada como sendo impossível o Senado Federal ampliar, interpretar ou restringir a extensão da decisão do STF.

Se toda a lei foi declarada inconstitucional pelo STF, em controle difuso, de modo incidental, se entender o Senado Federal pela conveniência da suspensão da lei, deverá fazê-lo “no todo”, vale dizer, em relação a toda a lei que já havia sido declarada inconstitucional, não podendo suspender menos do que o decidido pela Excelsa Corte.

Em igual sentido, se, por outro lado, o Supremo, no controle difuso, declarou inconstitucional apenas parte da lei, entendendo o SF pela conveniência para a suspensão, deverá fazê-lo exatamente em relação à “parte” que foi declarada inválida, não podendo suspender além da decisão do STF.

■ 6.6.4.2.4. Efeitos propriamente ditos

Desde que o Senado Federal suspenda a execução, no todo ou em parte, da lei levada a controle de constitucionalidade de maneira incidental e não principal, a referida suspensão atingirá a todos, porém valerá a partir do momento que a resolução do Senado for publicada na Imprensa Oficial.

O nome ajuda a entender: *suspender a execução* de algo que vinha produzindo efeitos significa dizer que se suspende a partir de um momento, não

fazendo retroagir para atingir efeitos passados. Por exemplo, quem tiver interesse em “pedir de volta” um tributo declarado inconstitucional deverá mover a sua ação individualmente para reaver tudo antes da Resolução do Senado, na medida em que ela não retroage.

Assim, os efeitos serão *erga omnes*, porém *ex nunc*, não retroagindo. [83](#)

Destaca-se o art. 1.º, § 2.º, do [Decreto n. 2.346/97](#), que, expressamente, fixa a produção de efeitos *ex tunc*, exclusivamente em relação à **Administração Pública Federal direta e indireta**, na hipótese de haver a edição de **resolução do Senado Federal**, suspendendo a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

Referido decreto, em seu art. 1.º, § 3.º, ainda estabelece que o Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União, poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso concreto.

■ 6.6.4.2.5. O Senado é obrigado a suspender os efeitos?

Essa questão é muito debatida na doutrina. Tanto que nos limitaremos a apontar nosso posicionamento, que coincide com o do STF, Senado Federal e grande parte da doutrina, devendo, pois, ser o observado nas provas preambulares.

Deve-se, pois, entender que o Senado Federal *não está obrigado a suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal*. Trata-se de discricionariedade política, tendo o Senado Federal total liberdade para cumprir o art. 52, X, da CF/88. Caso contrário, estaríamos diante de afronta ao princípio da separação de Poderes.

Uma vez editada a resolução, não nos parece possível a sua posterior revogação pelo próprio Senado Federal com o objetivo de se restabelecer a eficácia da norma declarada inconstitucional no controle difuso. No caso, o restabelecimento da norma dependeria de nova atuação pelo Poder Legislativo editando um novo ato. A **resolução** que suspende o ato declarado

inconstitucional é **irrevogável**.⁸⁴

■ 6.6.5. Teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso: análise crítica — abstrativização do controle difuso? — tendência para uma maior expansividade das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias individuais. Limitação do cabimento da reclamação.⁸⁵ Perspectivas do controle incidental em controle concentrado

ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO?		
■ Gilmar Mendes ■ Eros Grau	■ Teori Zavascki ■ Luís Roberto Barroso ■ Rosa Weber ■ Celso de Mello	■ Sepúlveda Pertence ■ Joaquim Barbosa ■ Ricardo Lewandowski ■ Marco Aurélio
Entendimento	Entendimento	Entendimento
■ SIM ■ art. 52, X — reconhecimento de mutação constitucional ■ o Senado Federal daria simplesmente publicidade à decisão de inconstitucionalidade declarada de modo incidental no controle difuso pelo STF ■ esses 2 Ministros conheceram	■ NÃO ■ preservação da regra estabelecida no art. 52, X — não acolhimento da tese da mutação constitucional ■ reconhecimento de fato superveniente, qual seja, a SV 26/2009 — aplicação do art. 462, CPC/73	■ NÃO ■ preservação da regra estabelecida no art. 52, X — não acolhimento da tese da mutação constitucional ■ utilização da súmula vinculante para se dar efeitos <i>erga omnes</i> ■ esses 4 Ministros

■ esses 2 Ministros conheceram e julgaram procedente a reclamação ■	CPC/73 ■ esses 4 Ministros conheceram e julgaram procedente a reclamação	concederam HC de ofício e não conheceram da reclamação ■
8 Ministros contra 2 entendem que não houve mutação constitucional do art. 52, X		
RCL 4.335, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.03.2014, DJE de 22.10.2014		

■ 6.6.5.1. Abstrativização do controle difuso?

Como sabemos, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil é jurisdicional misto, tanto *difuso* como *concentrado*.

No controle **difuso**, a arguição de inconstitucionalidade se dá de modo **incidental**, constituindo **questão prejudicial**. No controle **concentrado** (ADI genérica), por sua vez, a declaração se implementa de modo **principal**, constituindo o **objeto** do julgamento.

A doutrina clássica sempre sustentou, com **Buzaid**⁸⁶ e **Grinover**, que, “se a declaração de inconstitucionalidade ocorre incidentalmente, pela acolhida da questão prejudicial que é fundamento do pedido ou da defesa, a decisão não tem autoridade de coisa julgada, nem se projeta, mesmo *inter partes* — fora do processo no qual foi proferida”.⁸⁷

Contudo, respeitável parte da doutrina e alguns julgados do STF (“Mira Estrela”⁸⁸ e “progressividade do regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos”⁸⁹) e do STJ⁹⁰ propunham uma **nova interpretação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso** pelo STF.

Na doutrina, em importante estudo, **Gilmar Mendes** afirma ser “... possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma **autêntica mutação constitucional** em razão da completa **reformulação do sistema jurídico** e, por conseguinte,

de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica ‘**reforma da Constituição sem expressa modificação do texto**’ (Ferraz, 1986, p. 64 *et seq.*, 102 *et seq.*; Jellinek, 1991, p. 15-35; Hsü, 1998, p. 68 *et seq.*)”.[91](#)

Nessa mesma linha, **Teori Albino Zavascki**, também em sede doutrinária, sustenta a transcendência, com caráter vinculante, de decisão sobre a constitucionalidade da lei, **mesmo em sede de controle difuso**.[92](#)

Lúcio Bittencourt, em tese arrojada, muito embora demonstrasse conhecimento da doutrina de Liebman e da distinção entre *autoridade da coisa julgada* e *eficácia natural da sentença*, chegou a afirmar, inspirado pela regra do *stare decisis* norte-americano, que **a declaração de inconstitucionalidade no caso concreto e no controle difuso brasileiro (já que inexistente à época de seu estudo o controle concentrado por meio de ADI, enfatize-se)**, reconhecendo a invalidade da lei, **teria eficácia para todos**.[93](#)

Os principais argumentos a justificar esse novo posicionamento podem ser assim resumidos:

força normativa da Constituição;

princípio da supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os destinatários;

o STF enquanto guardião da Constituição e seu intérprete máximo;

dimensão política das decisões do STF.

A esses fundamentos, poderíamos acrescentar os **princípios da integridade e da coerência da jurisprudência dos Tribunais** e, no caso, da jurisprudência da Suprema Corte, introduzidos no art. 926, *caput*, do Novo CPC/2015, por sugestão de Lenio Streck e que fazem parte dos, denominados pelo autor, **“princípios-padrões”** que devem ser obedecidos nas decisões judiciais.[94](#)

Os tribunais também têm discutido o tema. No julgamento do **RE 197.917** (redução do número de vereadores — “Mira Estrela”), nos termos do voto do **Ministro Celso de Mello**,[95](#) o Ministro Gilmar Mendes “... ressaltou a aplicabilidade, ao E. Tribunal Superior Eleitoral, do **efeito vinculante** emergente da própria *ratio decidendi* que motivou o julgamento do precedente

mencionado”.[96](#)

Nessa linha, em seu voto, **vencido**, no julgamento da **RCL 4.335** (cf. *item 14.10.28.1*), o Ministro Gilmar Mendes “sepultou”, de vez, a regra do art. 52, X, aproximando o controle difuso do controle concentrado, traduzindo importante perspectiva em termos de **“abstrativização”** do controle difuso e de consagração da tese da transcendência da *ratio decidendi*.

Conforme afirma, “... parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples **efeito de publicidade**. Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este **publique** a decisão no *Diário do Congresso*. Tal como assente, não é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. **A própria decisão da Corte contém essa força normativa**. (...) Assim, o Senado não terá a faculdade de publicar ou não a decisão, uma vez que não se cuida de uma decisão substantiva, mas de simples dever de publicação, tal como reconhecido a outros órgãos políticos em alguns sistemas constitucionais (...) Portanto, a não publicação, pelo Senado Federal, de Resolução que, nos termos do art. 52, X, da Constituição, suspenderia a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF, não terá o condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia jurídica” (fls. 55-56 do acórdão).

Essa perspectiva, contudo, sempre foi **veementemente criticada** por vários autores, entre eles **Alfredo Buzaid**, que não admitia a qualidade da imutabilidade para as questões prejudiciais decididas incidentalmente no processo (art. 469, III, do CPC/73 — entendimento esse mantido no CPC/2015 na medida em que a regra do art. 503, § 1.º, não se aplica, já que o juízo no controle difuso não teria competência em razão da matéria para apreciar referida questão incidental como principal).[97](#)

Embora a tese da transcendência decorrente do controle difuso pareça bastante **sedutora, relevante** e **eficaz**, inclusive em termos de **economia**

bastante **sedutora, relevante e eficaz**, inclusive em termos de **economia processual**, de **efetividade do processo**, de **celeridade processual** (art. 5.º, LXXVIII — **Reforma do Judiciário**) e de implementação do princípio da **força normativa da Constituição** (Konrad Hesse), afigura-se faltar, ao menos em sede de controle difuso, dispositivos e regras constitucionais, para a sua implementação.

O **efeito erga omnes** da decisão foi previsto somente para o **controle concentrado** e para a **súmula vinculante** (EC n. 45/2004) e, em se tratando de controle difuso, nos termos da regra do **art. 52, X, da CF/88**, somente após atuação discricionária e política do Senado Federal.

No controle difuso, portanto, não havendo suspensão da lei pelo Senado Federal, a lei continua válida e eficaz, só se tornando nula no caso concreto, em razão de sua não aplicação.

Assim, na medida em que a análise da constitucionalidade da lei no controle difuso pelo STF não produz efeito vinculante, parece que somente mediante necessária **reforma constitucional** (modificando o art. 52, X, e a regra do art. 97) é que seria possível assegurar a constitucionalidade dessa nova tendência — repita-se, **bastante “atraente”** — da transcendência dos motivos determinantes no controle difuso, com caráter vinculante.

Admitir que o STF interprete no sentido de ter havido mutação do art. 52, X, e, assim, transformar o Senado Federal em órgão para simples publicidade da decisão concreta é sustentar **inadmitida mutação inconstitucional**. Ao STF, não foi dado o poder de reforma.

A possibilidade de se atribuir o efeito *erga omnes* dependeria ou de **resolução do Senado Federal** ou, ainda, de **súmula vinculante** a ser editada pelo STF o que, em nosso entender, seria muito mais legítimo e eficaz, além de respeitar a segurança jurídica, evitando-se o casuísmo.

Nessa linha, cumpre observar que o STF, consolidando o entendimento fixado no HC 82.959, no sentido de observância ao princípio da **individualização da pena** (art. 5.º, XLVI), editou, em 16.12.2009, com efeito *erga omnes* e vinculante, a **SV 26/2009** (DJE de 23.12.2009), que tem o seguinte teor: “para

equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.[98](#)

Nesse tema, **2** Ministros, Gilmar Mendes e Eros Grau, sustentavam, no caso concreto da RCL 4.335, a partir do julgamento do referido HC, mesmo sem a edição da súmula vinculante, o efeito transcendente e *erga omnes* da decisão (tese da mutação constitucional do art. 52, X). Por sua vez, Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio não admitiam a mutação constitucional e, assim, para o efeito *erga omnes*, a necessidade de resolução do Senado Federal ou a edição de súmula vinculante. Como esses **4** concordavam com a tese da inconstitucionalidade do regime fechado, não conheceram da reclamação, mas concederam *habeas corpus* de ofício.

Com o voto-vista do Min. Teori Zavascki, devolvido em **20.03.2014**, acompanhado pelos Mins. Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello, no julgamento da referida RCL 4335-AC, esses outros **4** Ministros julgaram procedente a RCL não em razão da tese da abstrativização, mas diante da existência de **fato superveniente** (art. 462, CPC/73, correspondente ao art. 493 do CPC/2015), qual seja, a **SV 26**.

Deve-se deixar bem claro que o Min. Teori Zavascki, muito embora admitisse — o que concordamos — uma **inegável expansividade das decisões do STF**, mesmo quando tomadas em controvérsias de índole individual, esse reconhecimento não seria suficiente para fundamentar o cabimento da reclamação com base no art. 102, I, “I”, sob pena de transformar a Corte em órgão recursal. Assim, sustentou uma necessária **interpretação estrita** dessa competência, sob pena de se caracterizar acesso *per saltum* à Suprema Corte e combatida supressão de instância. Vejamos:

“O mesmo **sentido restritivo** há de ser **conferido à norma de competência sobre cabimento de reclamação**. É que, considerando o vastíssimo elenco de decisões da Corte Suprema com eficácia expansiva, e a tendência de

universalização dessa eficácia, **a admissão incondicional de reclamação em caso de descumprimento de qualquer delas, transformará o Supremo Tribunal Federal em verdadeira Corte executiva**, suprimindo instâncias locais e atraindo competências próprias das instâncias ordinárias. Em outras palavras, **não se pode estabelecer sinonímia entre força expansiva e eficácia vinculante *erga omnes* a ponto de criar uma necessária relação de mútua dependência entre decisão com força expansiva e cabimento de reclamação**. Por outro lado, conforme ficou decidido na Reclamação (AgRg) 16.038 (Min. Celso de Mello, 2.^a T., j. 22.10.2013) ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’” (fls. 168 do acórdão — original sem grifos).

Assim, muito embora o STF tenha, por maioria de 6 x 4, conhecido e julgado procedente a reclamação, entre esses 6 Ministros (no sentido de procedência da reclamação), apenas os Mins. Gilmar Mendes e Eros Grau fundamentaram com base na tese da mutação.

Deve-se deixar claro, então, que **8 Ministros** (os outros 4 dos 6 que conheciam da reclamação, bem como os 4 que não conheciam da reclamação) pronunciaram, acertadamente, no sentido de **não se admitir a mutação do art. 52, X**. Em outras palavras, o efeito *erga omnes* no controle difuso **ainda** depende de resolução do Senado Federal (ou de **súmula vinculante** do STF), que, por sua vez, não se transformou, deixe-se claro, em mero “menino de recado”.

Reconhecemos e admitimos, retomando esse ponto, uma **inegável expansividade** das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias individuais, bem como uma dita **objetivação** do processo subjetivo (nesse sentido, o voto do Min. Teori na RCL 4.335 é bastante profundo). Contudo, a mudança pretendida em relação ao art. 52, X, que, aliás, parece ser uma tendência, necessariamente, **depende de formal reforma constitucional**.

■ **6.6.5.2. Eficácia expansiva das decisões. Objetivação do recurso extraordinário. Limites à reclamação constitucional. Inconstitucionalidades no CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)**

Em relação ao tema exposto (eficácia expansiva das decisões e objetivação do recurso extraordinário), gostaríamos de destacar alguns exemplos dessa perspectiva para, ao final, concluir, reforçando o item anterior, que, para o uso específico da **reclamação constitucional**, devemos adotar uma **postura mais restritiva**, sob pena de tornar o STF uma Corte de revisão, um órgão recursal, tendo em vista a criação de um inadmissível (porque **inconstitucional**) atalho processual. Vejamos os exemplos a demonstrar a inegável e muito bem-vinda **valorização dos precedentes**:

CPC/73	REGRA CPC/73	CPC/2015	REGRA/CORRESPONDÊNCIA/NO CPC/2015
■ art. 120, parágrafo único	■ possibilidade de o relator decidir de plano o conflito de competência havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada	■ art. 955	■ deixa claro que a jurisprudência dominante é do STF, STJ ou do Tribunal ■ aumenta o poder decisório do STF quando a tese tiver sido firmada no julgamento de casos repetitivos incidente de assunção de competência
	■ improcedência de plano — julgamento de mérito sem a		■ houve ampliação dos poderes da primeira instância, permitindo o julgamento de mérito não somente em relação às decisões do juízo, mas também em hipóteses de: - I — enunciado de súmula do STF ou

■ art. 285-A	de mérito sem a citação do réu se já houver demandas idênticas no juízo	■ art. 332	II — acórdão proferido pelo STF ou em julgamento de recursos repetitivos III — entendimento firmado em incidência de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV — enunciado de súmula de Tribunal do direito local.
■ art. 475, § 3.º	■ inexistência de reexame necessário quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente	■ art. 496, §§ 3.º e 4.º	■ dispensa da remessa necessária quando o valor da causa não exceder o valor do acordo com os valores da causa (novidade) ■ mantém a ideia de dispensa em decisões do STF e do STJ e irrelação a entendimento firmado em assunção de competência ■ inova, também, de maneira interessante, ao dispensar o reexame necessário quando a sentença estiver fundamentada em entendimento coincidente com o entendimento vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidando a ideia de manifestação, parecer ou decisão administrativa
■ art. 475-L, § 1.º	■ impugnação à fase executiva no cumprimento de sentença para declarar a inexigibilidade do título quando houver	■ art. 525, §§ 12 a 15	■ mantém a ideia com as observações críticas que fizemos no <i>item 6.7</i> deste estudo

	inconstitucionalidade da lei que funda o título		
■ art. 741, parágrafo único	■ impugnação na execução contra a Fazenda Pública para declarar a inexigibilidade do título quando houver declaração de inconstitucionalidade da lei que funda o título	■ art. 535, §§ 5.º a 8.º	■ mantém a ideia com as observações críticas que fizemos no <i>item 6.7</i> deste estudo
■ art. 479	■ recomendação para a uniformização da jurisprudência	■ art. 926	■ os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
■ art. 481, § 1.º	■ dispensa da cláusula de reserva de plenário no controle difuso	■ art. 949, parágrafo único	■ regra prevista de modo idêntico
■ art. 518, § 1.º	■ espécie de súmula impeditiva de recurso, caracterizada como um pressuposto de admissibilidade negativo do recurso, já que o juiz não	■ art. 1.011, I, c/c art.	■ a admissibilidade negativa é tratada apenas para o Relator no Tribunal, e não para o juízo <i>a quo</i> que proferiu a sentença, decidindo monocraticamente (no Novo CPC não há mais juízo de admissibilidade — art. 1.011, I, c/c art. 1.012, 3.º)

■ art. 518, § 1.º	negativo do recurso, já que o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do STJ ou do STF	1.011, I, c/c art. 932, IV	■ na linha das novidades do CPC Relator poderá negar provimento ao recurso quando for contrário a: súmula do STF ou do STJ; acórdão proferido pelo STF ou em julgamento de recursos repetidos; entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência
■ arts. 543-A, 543-B e 543-C	■ análise da repercussão geral no recurso extraordinário. Julgamento por amostragem — processos-modelos tanto no recurso extraordinário como no especial	■ arts. 1.035 e 1.036 segs.	■ a regra da repercussão geral foi reforçada e mais bem disciplinada a técnica de julgamento de recursos extraordinários e especiais repetidos
■ arts. 544, § 4.º, I e II, e 557, caput e § 1.º-A	■ atribuição dada ao relator do agravo em recurso especial ou extraordinário para, monocraticamente, com base em jurisprudência do STJ ou do STF, conhecer do agravo e provê-lo ou negar-lhe seguimento. Essa previsão está	■ art. 932, IV e V	■ poderes dados ao relator para negar provimento ao recurso ou dar provimento ao recurso com base em razão de súmula do STF ou do STJ, em julgamento de recursos repetidos e em entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência

	explícita, também, para os recursos em geral (art. 557)		
■ art. 555, § 1.º	■ ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso	■ art. 947	■ o novo Código criou um capítulo para o que chamou de incidente de assunção de competência — IAC ■ o art. 947, § 3.º, prevê que o proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e fracionários, exceto se houver rejeição, fazendo a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância do referido precedente (art. 988, IV)
■ não há correspondência	■ não há correspondência	■ art. 927, III, IV e V	■ Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V — a orientação do plenário ou do órgão especial acórdão

			estiverem vinculados
--	--	--	----------------------

Analisados os dispositivos normativos acima listados, não temos dúvidas em reconhecer, tanto no CPC/73 como no de 2015, o **inegável processo de expansividade das decisões proferidas em casos concretos**, bem como a **força dada à jurisprudência dos tribunais**.

Todos os exemplos indicam uma inegável tendência de **valorização dos precedentes**, na linha do que o CPC/2015 denominou **jurisprudência dos tribunais estável, íntegra e coerente** (art. 926, *caput*).

Aliás, devemos destacar que o texto original do Senado Federal estabelecia apenas uma valorização da **estabilidade** da jurisprudência. A previsão da **integridade** e da **coerência** se verificou em razão de sugestão feita por Lenio Streck à comissão de especialistas na Câmara dos Deputados (por todos, Fredie Didier), bem como ao Relator, Deputado Paulo Teixeira, e que veio a ser acatada pelo Senado Federal, na votação final do substitutivo.

Devemos, então, analisar a amplitude dessa dita **“emenda streckiana-dworkiniana”** ao projeto de lei (assim chamada por Streck),⁹⁹ especialmente no sentido de se verificar a amplitude da vinculação da jurisprudência dos tribunais em relação aos juízes do Brasil e a potencialização supostamente dada para o cabimento da **reclamação constitucional**.

Em primeiro lugar, temos que aplaudir essa importante potencialização dada à jurisprudência no CPC/2015, ao prever um sentido bastante técnico desses **vetores principiológicos** a partir de uma concepção de **dignidade da pessoa humana**, considerando os princípios da **segurança jurídica**, da **proteção da confiança** e da **isonomia** (art. 927, § 4.º, CPC/2015).

Para Streck, “a estabilidade é diferente da integridade e da coerência do Direito, pois a **‘estabilidade’ é um conceito autorreferente, isto é, numa relação direta com os julgados anteriores**. Já a **integridade** e a **coerência** guardam um substrato ético-político em sua concretização, isto é, são dotadas de consciência histórica e consideram a facticidade do caso”.¹⁰⁰ Nesse sentido, o

■ **coerência:** “... em casos semelhantes, deve-se proporcionar a garantia da **isonômica aplicação principiológica**. Haverá coerência se os mesmos princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos. A coerência assegura a **igualdade**, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte dos juízes. Isso somente pode ser alcançado através de um **holismo interpretativo**, constituído a partir do **círculo hermenêutico**”; [101](#)

integridade: segundo o autor, valendo-se das lições de Dworkin (*O império do direito*, Quartier Latim, 2008, p. 213), é duplamente composta: **a) princípio legislativo**, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente; **b) princípio jurisdicional**, que demanda que a lei, tanto quanto o possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito. Trata-se de uma garantia contra arbitrariedades interpretativas. A integridade limita a ação dos juízes; mais do que isso, coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é uma forma de virtude política. A integridade significa rechaçar a tentação da arbitrariedade”. [102](#) E, no citado texto de 18.12.2014, Streck chegou a afirmar ser a integridade **antitética ao voluntarismo, ao ativismo e à discricionariedade**.

Pois bem, definido esse **novo sentido da jurisprudência**, resta analisar a amplitude da vinculação dos juízes e tribunais e, no caso, o cabimento ou não desse inegável direito fundamental (verdadeiro direito de petição — art. 5.º, XXXIV, “a”), denominado **reclamação constitucional**.

Pelos dispositivos normativos citados no quadro acima, o CPC/2015 seguiu a tendência que já se verificava em relação às últimas minirreformas do Código Buzaidiano de 1973, aumentando o poder decisório dos relatores e a “vinculação” sugestiva decorrente de posicionamentos já sumulados e pacificados nos tribunais superiores.

O CPC/2015, contudo, avançou e **supervalorizou o cabimento da reclamação** e, assim, o **efeito vinculante das decisões**.

De acordo com o **art. 988, IV, CPC/2015**, caberá reclamação da parte

De acordo com o **art. 988, IV, CPC/2015**, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de precedente proferido em **julgamento de casos repetitivos** ou em **incidente de assunção de competência**.

Por sua vez, o **art. 985, § 1.º, CPC/2015**, reforça que caberá reclamação se não observada a tese adotada no incidente de resolução de demandas repetidas (IRDC).

Em nosso entender, essas regras de vinculação e o consequente cabimento da reclamação constitucional não poderiam ter sido introduzidos por legislação infraconstitucional, mas, necessariamente, por **emenda constitucional** a prever outras hipóteses de decisões com efeito vinculante, além daquelas já previstas na Constituição.

Como se sabe, na CF/88, o **efeito vinculante** (no caso, premissa para se falar nessa hipótese de cabimento da reclamação), somente se observa em razão das decisões em **controle concentrado de constitucionalidade** (art. 102, § 2.º), [103](#) ou em **razão de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante** (art. 103-A), [104](#) regra essa, aliás, na linha do que sustentamos, introduzida pela **EC n. 45/2004**.

Não podemos confundir **efeitos processuais** dos instrumentos elencados acima com ampliação das **hipóteses de cabimento da reclamação constitucional** (art. 102, I, “I”) para a garantia da autoridade das decisões dos tribunais.

Até podemos admitir, aplicando-se os instrumentos de **coerência** e **integridade**, o que, de modo muito interessante, Streck denominou **“vinculação orgânica-material”** [105](#) dos julgadores.

Entretanto, essa dita “vinculação”, no controle da decisão judicial, **não poderá ensejar o cabimento da reclamação constitucional**. Trata-se de norma de caráter programático, e não de imposição. Busca-se criar uma cultura de observância dos precedentes, mas não a hipótese de reclamação constitucional que não encontra fundamento na Constituição.

Como se disse, sem dúvida, ferramentas processuais serão importantes para

abreviar a entrega da prestação jurisdicional (aliás, como sabemos, a **razoável duração do processo** é direito fundamental — art. 5.º, LXXIII, CF/88). Exemplificando, é perfeitamente admissível a introdução por lei de julgamento monocrático pelo relator no tribunal em observância à jurisprudência dominante do STF ou do STJ, ou a restrição das hipóteses de remessa necessária.

Contudo, isso não pode significar o cabimento da reclamação constitucional. Assim, entendemos, **flagrantemente inconstitucional** essa pretensão trazida no CPC/2015.

Estamos nos referindo aos **arts. 988, IV** (excetuando-se, naturalmente, a hipótese da súmula vinculante), **985, § 1.º**, e **947, § 3.º**, e, também, ao **art. 927, III, IV e V** (CPC/2015), ao se estabelecer que os juízes e tribunais observarão:

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Dizer que “devem” observar significa vincular. Não poderia ser outra a interpretação, pois, do contrário, não faria sentido explicitar o dever de “observar” ao lado de outros incisos que, por sua essência, já trazem, ínsitos, a vinculação, como são os incisos I (**decisões do STF em controle concentrado**) e II (**enunciados de súmula vinculante**), em relação aos quais inquestionável o cabimento da reclamação constitucional.

O art. 947, § 3.º, aliás, expressamente, estabelece que o acórdão proferido em assunção de competência **vinculará** todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. **Criam-se hipóteses de vinculação por lei**. Esse é o problema, pois a previsão de efeito vinculante enseja o cabimento da reclamação (muito embora nem todas as hipóteses do art. 927, III, IV e V, estejam descritas no art. 988, entendemos que as que não se encontram explicitadas neste

dispositivo, em razão do dito efeito vinculante, correriam o risco de serem “reclamadas” com fundamento na previsão genérica do art. 988, II, no caso, para a garantia das decisões do tribunal ou na previsão genérica do inciso IV quando fala em “casos” repetidos, e não no instituto do “incidente de resolução de demandas repetidas”).

Não estamos a condenar os efeitos processuais, aliás, **muito bem-vindos** e uma realidade já no CPC/73 em razão de suas minirreformas. Estamos, por outro lado, unicamente **a não reconhecer o efeito vinculante para o cabimento da reclamação constitucional.**

Entendemos que essa é a linha da interpretação do STF, conforme se verificou no julgamento da **RCL 4.335** (cf. *item 6.6.5.1*).

No voto do Min. Teori Zavascki, ficou clara a necessidade, muito embora reconhecida a eficácia expansiva das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias concretas e individuais, de se dar uma interpretação estrita à reclamação constitucional, sob pena de transformar o STF em Corte de revisão, em órgão recursal, tendo em vista a criação de um inadmissível (porque **inconstitucional**) atalho processual ou, ainda, um acesso *per saltum* à Suprema Corte em combatida supressão de instância.

Esse ponto específico da reclamação não foi vetado pela Presidente da República (**Lei n. 13.105, de 16.03.2015**). Resta aguardar, então, como o STF vai enfrentar essa questão (**pendente**).

■ **6.6.5.3. Controle incidental em controle concentrado abstrato e o seu efeito “erga omnes” — eficácia da decisão do STF**

Como se sabe, no **controle difuso** a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo **incidental** e se caracteriza como **questão prejudicial incidental**. Ou seja, julga-se procedente ou improcedente o pedido formulado tendo em vista a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei ou ato normativo. A inconstitucionalidade, nesse caso, não é o pedido, mas a causa de pedir. Dessa forma, na sentença a ser proferida, o dispositivo contém a “resposta”

fundamentação.

Por outro lado, no **controle concentrado** a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo **principal** e é o próprio pedido formulado na ação (ADI) que se fundamenta em violação formal ou material à Constituição. Por exemplo, uma lei que cria cargo sem a observância do princípio do concurso público é inconstitucional por violar o art. 37, II, da CF/88.

Agora, imaginemos que em determinado controle concentrado e em abstrato, ao se verificar os fundamentos para nulificar ou não uma lei, entenda o STF que outro ato normativo, que não fazia parte do pedido, é inconstitucional.

É como se estivéssemos diante do procedimento de cisão previsto para o controle difuso, no qual, diante de questão de ordem suscitada, paralisa-se o julgamento, cinde-se o processo e encaminha-se a análise da inconstitucionalidade para o Pleno do Tribunal (art. 97 — cláusula de reserva de plenário).

Avançando, vamos supor que essa questão de ordem a ser resolvida seja suscitada não no controle difuso, mas em determinada ADI (controle concentrado).

Estamos diante da problemática que surgiu no julgamento da **ADI 4.029**, que tinha por objeto a Lei n. 11.516/2007, fruto de conversão da MP n. 366/2007 e que dispôs sobre a criação do *Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)*, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Dentre os vários argumentos discutidos na referida ADI, estava a tese do **vício formal**, por violação ao **art. 62, § 9.º, da CF/88**, que estabelece ser atribuição de **comissão mista** de Deputados e Senadores **examinar** as medidas provisórias e sobre elas **emitir parecer**, de caráter **opinativo**, acrescente-se, antes de serem **apreciadas**, em **sessão separada**, pelo **plenário** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

No caso concreto, referida MP foi convertida na lei objeto da ADI **sem** a

No caso concreto, referida MP foi convertida na lei objeto da ADI **sem** a apreciação pela comissão mista de Deputados e Senadores, havendo apenas a emissão de **parecer individual de seu relator**, nos termos do art. 6.º, § 2.º, **106** da Res. n. 1/2002-CN.

Segundo ficou estabelecido na ementa do acórdão, “as comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem da **necessidade**, imposta pela Constituição, de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo Plenário seja feita de maneira inopinada, percebendo-se, assim, que o **parecer** desse colegiado representa, em vez de formalidade desimportante, uma **garantia de que o Legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo Executivo**. O art. 6.º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela Comissão Mista, diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, é **inconstitucional**” (**ADI 4.029**, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2012, Plenário, *DJE* de 27.06.2012).

Dessa forma, embora a lei objeto da ADI tivesse seguido o procedimento de tramitação das medidas provisórias previsto na **Res. n. 1/2002-CN**, entendeu o Tribunal que referido procedimento não se conforma ao art. 62, § 9.º, da CF/88.

Decidiu então a Corte declarar **incidentalmente a inconstitucionalidade** dos **arts. 5.º, caput, e 6.º, caput, e §§ 1.º e 2.º**, da **Res. n. 1/2002-CN**.

Por consequência, todas as medidas provisórias já convertidas em lei ou mesmo em tramitação que não tivessem observado o procedimento do art. 62, § 9.º (necessidade de apreciação pela comissão mista, não bastando manifestação unipessoal de relator), seriam inconstitucionais.

O interessante é que a **declaração incidental de inconstitucionalidade** (muito embora em controle concentrado e em ADI genérica), produziria efeitos *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, acarretando a inconstitucionalidade de centenas de medidas provisórias que não observaram o citado procedimento constitucional, apesar de não serem objeto na ação direta de inconstitucionalidade em julgamento.

É como se houvesse a ampliação de efeitos da decisão, a partir de **declaração incidental**, atingindo vários atos normativos que não eram objeto da ADI, em nítido privilégio da eficácia da decisão da Corte. Ou seja, o efeito *erga omnes, ex tunc* e vinculante decorria da declaração incidental (e, repita-se, apenas para deixar bem claro, em **CONTROLE CONCENTRADO E EM ABSTRATO**, e não em controle difuso — apesar de estarmos tratando desse assunto em seção do livro que cuida do controle difuso).

O que estamos procurando mostrar é essa **tendência de ampliação dos efeitos da decisão**. Seria como se a decisão que estabeleceu a imprescindível necessidade de análise pela comissão mista estivesse sendo veiculada em súmula vinculante e acarretando a nulificação de diversos atos normativos que não eram o objeto da ADI genérica.

Diante dessa consequência do resultado da declaração incidental, que repercutiria sobre os mais diversos setores da vida do País, decidiu o Tribunal, aplicando o art. 27 da Lei n. 9.868/99, [107](#) modular os efeitos da decisão, dando **eficácia ex nunc** em relação à **pronúncia de nulidade dos dispositivos da resolução do Congresso Nacional**, passando a exigir o respeito ao art. 62, § 9.º, somente a partir daquela decisão. Assim, todas as leis aprovadas de acordo com o procedimento da Res. n. 1/2002 que dispensaram a emissão de parecer pela comissão mista foram declaradas, por esse aspecto, **constitucionais**.

Podemos afirmar, dessa forma, que o modelo de apreciação da medida provisória fixado na resolução do Congresso Nacional foi declarado **“ainda constitucional”** até o julgamento da referida ADI 4.029 e, a partir de então, o STF declarou inconstitucional qualquer inobservância ao art. 62, § 9.º, da CF/88, ficando, por consequência, **preservadas a validade e a eficácia** de todas as medidas provisórias convertidas em lei até aquela data, bem como daquelas que estavam tramitando no Legislativo nos termos do procedimento fixado nos arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN, que permitiam a continuidade do iter procedimental de apreciação da medida provisória mesmo na hipótese de não haver parecer emitido pela comissão mista no prazo rígido de 14 dias contados da sua publicação.

■ 6.6.6. Controle difuso em sede de ação civil pública

Como vimos, o controle difuso de constitucionalidade é realizado no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário, produzindo, em regra, efeitos somente para as partes (salvo a hipótese de resolução do Senado Federal — art. 52, X), sendo a declaração de inconstitucionalidade proferida de modo incidental.

Portanto, só será cabível o controle difuso, em sede de ação civil pública “... como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a *controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal*” (Min. Celso de Mello, Rcl 1.733-SP, DJ de 1.º.12.2000 — Inf. 212/STF).

Por conseguinte, a jurisprudência do STF “... exclui a possibilidade do exercício da ação civil pública, quando, nela, o autor deduzir pretensão efetivamente destinada a viabilizar o controle abstrato de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo (RDA 206/267, Rel. Min. Carlos Velloso — Ag. 189.601-GO (AgRg), Rel. Min. Moreira Alves). Se, contudo, o ajuizamento da ação civil pública visar, não à apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito promover, *incidenter tantum*, o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do Poder Público. Incensurável, sob tal perspectiva, a lição de Hugo Nigro Mazzilli (‘O Inquérito Civil’, p. 134, item n. 7, 2. ed., 2000, Saraiva): ‘Entretanto, nada impede que, por meio de ação civil pública da Lei n. 7.347/85, se faça, não o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade das leis, mas, sim, seu controle difuso ou incidental. (...) assim como ocorre nas ações populares e mandados de segurança, nada impede que a inconstitucionalidade de um ato normativo seja objetada em ações individuais ou coletivas (não em ações diretas de inconstitucionalidade, apenas), como causa de pedir (não o próprio pedido)

dessas ações individuais ou dessas ações civis públicas ou coletivas” (Min. Celso de Mello, Rcl 1.733-SP, *DJ* de 1.º.12.2000 — *Inf.* 212/STF).

Mas atente à regra geral: **a ação civil pública não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, pois, em caso de produção de efeitos *erga omnes*, estaria provocando verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, usurpando competência do STF** (cf. STF, Rcl 633-6/SP, Min. Francisco Rezek, *DJ* de 23.09.1996, p. 34945).

No entanto, sendo os efeitos da declaração reduzidos somente às partes (sem amplitude *erga omnes*), ou seja, tratando-se de “... ação ajuizada, entre partes contratantes, na persecução de bem jurídico concreto, individual e perfeitamente definido, de ordem patrimonial, objetivo que jamais poderia ser alcançado pelo reclamado em sede de controle *in abstracto* de ato normativo” (STF, Rcl 602-6/SP), aí sim seria possível o controle difuso em sede de ação civil pública, verificando-se a declaração de inconstitucionalidade de modo incidental e restringindo-se os efeitos *inter partes*. O pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental terá, enfatize-se, de constituir verdadeira causa de pedir (cf. RE 424.993, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12.09.2007, *DJ* de 19.10.2007).

Como exemplo, de maneira precisa, Alexandre de Moraes cita determinada ação civil pública ajuizada pelo MP, em defesa do patrimônio público, para anulação de licitação baseada em lei municipal incompatível com o art. 37 da CF, declarando o juiz ou tribunal, no caso concreto, a inconstitucionalidade da referida lei, reduzidos os seus efeitos somente às partes. [108](#)

■ 6.7. CONTROLE CONCENTRADO [109](#)

O controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo recebe tal denominação pelo fato de “concentrar-se” em um único tribunal. Pode ser verificado em cinco situações:

--	--	--

AÇÃO	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL	REGULAMENTAÇÃO
■ ADI — Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica	■ art. 102, I, “a”	■ Lei n. 9.868/99
■ ADC — Ação Declaratória de Constitucionalidade	■ art. 102, I, “a”	■ Lei n. 9.868/99
■ ADPF — Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental	■ art. 102, § 1.º	■ Lei n. 9.882/99
■ ADO — Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão	■ art. 103, § 2.º	■ Lei n. 12.063/2009
■ IF109 — Representação Interventiva (ADI Interventiva)	■ art. 36, III, c/c art. 34, VII	■ Lei n. 12.562/2011

■ 6.7.1. ADI genérica

■ 6.7.1.1. Conceito (ADI genérica)

O que se busca com a **ADI genérica** é o controle de constitucionalidade de ato normativo em **tese, abstrato**, marcado pela **generalidade, impessoalidade e abstração**.

Ao contrário da via de **exceção ou defesa**, pela qual o controle (difuso) se verificava em casos concretos e incidentalmente ao objeto principal da lide, no **controle concentrado** a **representação de inconstitucionalidade**, em virtude de ser em relação a um ato normativo em tese, tem por objeto principal a

declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado. O que se busca saber, portanto, é se a lei (*lato sensu*) é inconstitucional ou não, manifestando-se o Judiciário de forma específica sobre o aludido objeto. A ação direta, portanto, nos dizeres da Professora Ada Pellegrini Grinover, “tem por objeto a própria questão da inconstitucionalidade, decidida *principaliter*”. [110](#)

Em regra, através do controle concentrado, almeja-se expurgar do sistema lei ou ato normativo viciado (material ou formalmente), buscando, por conseguinte, a sua **invalidação**.

■ 6.7.1.2. Objeto (ADI genérica)

O objeto do comentado instrumento processual é a **lei** ou **ato normativo** que se mostrarem incompatíveis com o sistema.

■ 6.7.1.2.1. Leis

Entendam-se por **leis** todas as espécies normativas do art. 59 da CF/88, quais sejam: *emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções*. [111](#)

■ 6.7.1.2.2. Atos normativos

Atos normativos, segundo Alexandre de Moraes, [112](#) podem ser: a) **resoluções administrativas dos tribunais**; b) **atos estatais de conteúdo meramente derogatório**, como as resoluções administrativas, desde que incidam sobre atos de caráter normativo.

O autor, valendo-se das palavras de Castanheira A. Neves, observa que poderá ser objeto de controle qualquer “ato revestido de **indiscutível caráter normativo**”, [113](#) motivo pelo qual incluímos aí os **regimentos internos dos tribunais**.

Podem, também, ser objeto de controle de constitucionalidade:

as **deliberações administrativas dos órgãos judiciários** (precedente: STF, ADI 728, Rel. Min. Marco Aurélio). Nesse sentido:

“EMENTA: Resolução administrativa do TRT da 3.^a Região. **Natureza normativa da resolução**. Atribuição do Congresso Nacional para ato normativo que aumenta vencimentos de servidor. Inconstitucionalidade da resolução configurada. Precedentes do STF” (ADI 1.614, Rel. p/ ac. Min. Nelson Jobim, j. 18.12.98, Plenário, DJ de 06.08.99). “É cabível o controle concentrado de resoluções de tribunais que deferem reajuste de vencimentos. Precedentes” (ADI 2.104, Rel. Min. Eros Grau, j. 21.11.2007, Plenário, DJE de 22.02.2008).

as **deliberações dos Tribunais Regionais do Trabalho judiciários** que determinam o pagamento a magistrados e servidores das diferenças de plano econômico (precedente: STF, ADI 681/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, reconhecendo o seu caráter normativo), **salvo** as convenções coletivas de trabalho; [114](#)

■ **resolução do Conselho Interministerial de Preços — CIP** (STF, Pleno, ADI 8-0/DF, Rel. Min. Carlos Velloso), que concedeu aumento de preço aos produtos farmacêuticos, permitindo, portanto, a verificação de sua compatibilidade com a Constituição Federal.

■ 6.7.1.2.3. **Súmulas?**

De acordo com a ADI 594-DF, só podem ser objeto de controle perante o STF leis e atos normativos **federais** ou **estaduais**. **Súmula** de jurisprudência não possui o grau de normatividade qualificada, não podendo, portanto, ser questionada perante o STF através do controle concentrado.

E a súmula vinculante pode ser objeto de ADI?

Como se sabe, a **EC n. 45/2004** fixou a possibilidade de o **STF** (e exclusivamente o STF), de ofício ou por provocação, mediante decisão de **2/3** dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar **súmula** que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá **efeito vinculante** em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração

Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 103-A).

O seu § 2.º, por seu turno, fixa a possibilidade de, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, proceder-se a **aprovação, revisão** ou **cancelamento** de súmula, mediante provocação daqueles que podem propor a **ação direta de inconstitucionalidade**.

Assim, tendo em vista o fato de a **súmula** não ser marcada pela generalidade e abstração, diferentemente do que acontece com as leis, não se pode aceitar a técnica do “controle de constitucionalidade” de súmula, mesmo no caso da súmula vinculante.

O que existe é um **procedimento de revisão** pelo qual se poderá **cancelar** a súmula. O cancelamento desta significará a não mais aplicação do entendimento que vigorava. Nesse caso, naturalmente, a nova posição produzirá as suas consequências a partir do novo entendimento, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Cabe alertar que o procedimento de **aprovação, revisão** ou **cancelamento** de súmula vinculante foi disciplinado pela Lei n. 11.417/2006.

Todavia, em algumas decisões, a Ministra Ellen Gracie entendeu que o mecanismo para se rever a súmula vinculante seria a própria ADI (com o que não concordamos, pelos motivos acima expostos). Tratava-se de hipótese na qual se discutia a impetração de *habeas corpus* tendo em vista a edição da **SV 11.115** sobre o uso de algemas (HC 96.301, 06.10.2008, Min. Ellen Gracie).

Em **05.12.2008**, o Presidente do STF, no uso de suas atribuições, editou a **Res. n. 388**, disciplinando o processamento de proposta de edição, revisão e cancelamento de súmulas. Estabelece-se a tramitação em forma eletrônica da proposta, que, em nosso entender, difere, em substância, do processo de ADI, o que corrobora a nossa posição acima exposta de se tratar de um **procedimento próprio e distinto da ADI**.

■ 6.7.1.2.4. *Emendas constitucionais?*

Como dissemos, as **emendas constitucionais** podem ser objeto de controle, embora introduzam no ordenamento normas de caráter constitucional. O que temos com o processo de emendas é a manifestação do **poder constituinte derivado reformador**, e, como vimos ao estudar a teoria do poder constituinte, a derivação dá-se em relação ao poder constituinte originário. Este último é ilimitado e autônomo. O derivado reformador, por seu turno, deve observar os limites impostos e estabelecidos pelo originário, como decorre da observância às regras do art. 60 da CF/88. Assim, desobedecendo aos referidos limites, inevitável declarar inconstitucional a emenda que introduziu uma alteração no texto constitucional. [116](#)

Conforme alertamos, o **poder constituinte derivado revisor** (art. 3.º do ADCT), assim como o **reformador** (art. 60 da CF/88) e o **decorrente** (art. 25 da CF/88 — Constituições estaduais), é fruto do trabalho de criação do originário, estando, portanto, a ele **vinculado**. É, ainda, um “poder” **condicionado** e **limitado** às regras instituídas pelo originário, sendo, assim, um **poder jurídico**.

Dessa maneira, as **emendas de revisão** também poderão ser “controladas”, tanto em seu aspecto formal (procedimento previsto no art. 3.º do ADCT) como material (cláusulas pétreas — art. 60, § 4.º, I a IV) (cf. *item 4.4.4*).

■ 6.7.1.2.5. *Medidas provisórias?*

Somente o ato estatal de conteúdo normativo, em plena vigência, pode ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade. Como a medida provisória tem força de lei, poderá ser objeto de controle, já que ato estatal, em plena vigência. No entanto, sendo ela convertida em lei, ou tendo perdido a sua eficácia por decurso de prazo, nos termos do art. 62, § 3.º, da CF/88 (confira as profundas alterações trazidas pela **EC n. 32/2001** em relação à tramitação das medidas provisórias e por nós comentadas no *item 9.14.4*), considerar-se-á prejudicada a ADI (que questionava a constitucionalidade da MP) pela perda do objeto da ação. [117](#) O autor da ADI, na primeira hipótese, deverá aditar o seu

pedido à nova lei de conversão.

E os requisitos constitucionais de relevância e urgência (art. 62) podem ser objeto de controle jurisdicional?

Excepcionalmente, o STF decidiu serem passíveis de controle desde que o exame seja feito *cum grano salis*, ou seja, com muita **parcimônia**. Assim, “conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em **caráter excepcional** se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2.º da CF) (ADI n. 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 23.04.2004; ADI n. 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 26.03.1999; ADI n. 1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 12.06.1998; ADI n. 162-MC, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 19.09.1997)” (ADC 11-MC, voto do Min. Cezar Peluso, j. 28.03.2007, *DJ* de 29.06.2007).

Esse entendimento foi **confirmado** pela Corte no julgamento da **ADI 4.029** (j. 08.03.2012), ficando assim estabelecido:

“EMENTA: (...). A atuação do Judiciário no controle da existência dos requisitos constitucionais de edição de Medidas Provisórias em **hipóteses excepcionais**, ao contrário de denotar ingerência contramajoritária nos mecanismos políticos de diálogo dos outros Poderes, **serve à manutenção da Democracia e do equilíbrio entre os três baluartes da República**. Precedentes (ADI 1.910 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, j. em 22.04.2004; ADI 1.647, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, j. em 02.12.98; ADI 2.736/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, j. em 08.09.2010; ADI 1.753 MC, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, j. em 16.04.98)”.

E os requisitos constitucionais de imprevisibilidade e urgência (art. 62 c/c o art. 167, § 3.º) da MP que abre crédito extraordinário [118](#) podem ser objeto de controle jurisdicional?

Dada a magnitude do julgamento, pedimos vênha para transcrever a ementa que resume a nova posição do STF, **revendo**, inclusive, a jurisprudência que

não admitia o controle para os denominados atos de efeito concreto (cf. *item 6.7.1.2.10*):

“EMENTA: Limites constitucionais à **atividade legislativa excepcional** do Poder Executivo na edição de **medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário**. Interpretação do art. 167, § 3.º c/c o art. 62, § 1.º, inciso I, alínea d, da Constituição. Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 62), a Constituição exige que a abertura do crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os requisitos de **imprevisibilidade** e **urgência** (art. 167, § 3.º) recebem **densificação normativa da Constituição**. Os conteúdos semânticos das expressões ‘guerra’, ‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ constituem **vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3.º c/c o art. 62, § 1.º, inciso I, alínea d, da Constituição**. ‘Guerra’, ‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ são conceitos que representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de consequências imprevisíveis para a ordem pública e a paz social, e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas singulares e extraordinárias. A leitura atenta e a análise interpretativa do texto e da exposição de motivos da MP n. 405/2007 demonstram que os créditos abertos são destinados a prover despesas correntes, que não estão qualificadas pela imprevisibilidade ou pela urgência. A edição da MP n. 405/2007 configurou um patente **desvirtuamento dos parâmetros constitucionais** que permitem a edição de medidas provisórias para a abertura de créditos extraordinários. Medida cautelar deferida. Suspensão da vigência da Lei n. 11.658/2008, desde a sua publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008” (**ADI 4.048-MC**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.05.2008, *DJE* de 22.08.2008). No mesmo sentido: **ADI 4.049-MC**, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05.11.2008 (*Inf. 527/STF*).

Essa nova posição mostra-se bastante relevante, freando o desvirtuamento dado pelo Executivo às medidas provisórias e, assim, “chamando” o Legislativo para que exerça, de maneira muito mais democrática, a análise da questão

orçamentária. Ou seja, a abertura de crédito tem de ser vista com muito critério.

■ 6.7.1.2.6. *Regulamentos subordinados ou de execução e decretos? Inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua*

Os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo Executivo (art. 84, IV, da CF) e demais atos normativos secundários poderiam ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade?

Como regra geral, **não!** Tais atos não estão revestidos de autonomia jurídica a fim de qualificá-los como atos normativos suscetíveis de controle,¹¹⁹ não devendo, assim, sequer ser conhecida a ação. Trata-se de **questão de legalidade**, e referidos atos, portanto, serão **ilegais** e não inconstitucionais.

Estamos diante daquilo que o STF chamou de **crise de legalidade**, caracterizada pela inobservância do dever jurídico de **subordinação normativa à lei**, escapando das balizas previstas na Constituição Federal (STF, Pleno, ADI 264/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *RTJ* 152/352; STF, ADI 1.253-3, medida liminar, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* 1, de 25.08.1995, p. 26022).

Nessas hipóteses, o objeto **não** seria ato normativo primário, com fundamento de validade diretamente na Constituição, mas ato secundário, com base na lei, não se admitindo, portanto, controle de inconstitucionalidade **indireta, reflexa** ou **oblíqua**.

“EMENTA: Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado *ultra legem*, quer porque tenha permanecido *citra legem*, quer, ainda, porque tenha investido *contra legem*, a questão caracterizará, sempre, típica **crise de legalidade**, e **não de inconstitucionalidade**, a inviabilizar, em consequência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma

potencial violação da Carta Magna, **ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua**, cuja apreciação **não se revela possível em sede jurisdicional concentrada**” (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.03.1994, Plenário, *DJ* de 06.05.1994). No mesmo sentido: ADI 3.805-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 22.04.2009; ADI 2.999, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.03.2008; ADI 365-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.11.1990.

O STF, **excepcionalmente**, conforme noticia *Alexandre de Moraes*, “tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamenta a lei, apresentando-se, assim, como **decreto autônomo**. Nessa hipótese, haverá possibilidade de análise de compatibilidade diretamente com a Constituição Federal para verificar-se a observância do *princípio da reserva legal*”. [120](#)

Em interessante precedente, estabelece a Suprema Corte: “Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado os atos normativos, expressões da função normativa, cujas espécies compreendem a função regulamentar (do Executivo), a função regimental (do Judiciário) e a função legislativa (do Legislativo). Os decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo não detém o monopólio da função normativa, mas apenas de uma parcela dela, a função legislativa” (ADI 2.950-AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, j. 06.10.2004, *DJ* de 09.02.2007). Confira, entre outros julgados:

“EMENTA: Impugnação de resolução do Poder Executivo estadual. Disciplina do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, consumo e assuntos análogos. Ato normativo autônomo. Conteúdo de lei ordinária em sentido material. Admissibilidade do pedido de controle abstrato. Precedentes. Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade o ato normativo subalterno cujo conteúdo seja de lei ordinária em sentido material e, como tal, goze de autonomia nomológica” (ADI 3.731-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.08.2007, *DJ* de 11.10.2007).

“EMENTA: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. **Impugnação de decreto autônomo**, que institui benefícios

fiscais. Caráter não meramente regulamentar. **Introdução de novidade normativa**. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se **autônomo** e, como tal, é **suscetível de controle concentrado de constitucionalidade...**” (ADI 3.664, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 1.º.06.2011, *DJE* de 20.09.2011).

■ 6.7.1.2.7. *Tratados internacionais*

Estudaremos no *item 9.14.5.2* (“Breves notas sobre o processo de formação dos tratados internacionais”) que o processo de incorporação no ordenamento jurídico interno dos **tratados internacionais** passa por quatro fases distintas, a saber: **a) celebração do tratado internacional** (negociação, conclusão e assinatura) pelo **Órgão do Poder Executivo** (ou posterior adesão [terceira etapa], art. 84, VIII — Presidente da República); **b) aprovação (referendo ou “ratificação” lato sensu)**, pelo Parlamento, do tratado, acordo ou ato internacional, por intermédio de **decreto legislativo**, resolvendo-o definitivamente (Congresso Nacional, art. 49, I); **c) troca ou depósito** dos instrumentos de **ratificação** (ou **adesão**, caso não tenha tido prévia celebração) pelo **Órgão do Poder Executivo** em âmbito internacional; **d) promulgação** por **decreto presidencial**, seguida da **publicação** do texto em português no *diário oficial*. Nesse momento o **tratado, acordo ou ato internacional adquire executoriedade no plano do direito positivo interno**, guardando estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias**.

Apesar de nossa opinião pessoal diferente,¹²¹ a maior parte da doutrina e pacificamente os tribunais (salvo alguns juízes do 1.º TACSP), inclusive, de forma majoritária, o STF, **entendiam** (sem qualquer distinção) que os tratados internacionais de qualquer natureza, mesmo sobre direitos humanos (esse entendimento vai ser superado), ingressam no ordenamento interno com o caráter de **norma infraconstitucional**, guardando estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias** editadas pelo Estado brasileiro (*RTJ* 83/809 e *Inf.* 73/STF — *DJ* de 30.05.1997), podendo, por conseguinte, ser revogados

(*ab-rogação* ou *derrogação*) por norma posterior e ser questionada a sua constitucionalidade perante os tribunais, de forma concentrada ou difusa. [122](#)

A **Reforma do Judiciário** (EC n. 45/2004) acrescentou um § 3.º ao art. 5.º, nos seguintes termos: “os tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** que forem aprovados, **em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, por **três quintos dos votos dos respectivos membros**, serão equivalentes às **emendas constitucionais**”.

A novidade trazida pela Reforma (e esse tema é ampliado no *item 9.14.5.2.2*, remetendo o leitor para a sua análise) consiste em diferenciar os *tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos* dos *tratados e convenções internacionais de outra natureza*. Aqueles (sobre direitos humanos), desde que aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional e em 2 turnos de votação (cf. art. 60, § 2.º), passam a ter **a mesma natureza jurídica das emendas constitucionais**. Isso significa que, inexistindo afronta aos “limites do poder de reforma”, o tratado internacional sobre direitos humanos, desde que observado o *quorum* diferenciado de aprovação pelo Congresso Nacional (igual ao das ECs), passa a ter **paridade normativa** com as **normas constitucionais**.

Finalmente, remetemos o leitor para o *item 9.14.5.2.3*, no qual discutimos a tese de **supralegalidade** dos tratados sobre direitos humanos defendida, inicialmente, pelo Ministro Gilmar Mendes (RE 466.343, *Inf. 449/STF*), sustentando serem mais que a lei, porém estando abaixo da Constituição.

Então, esquematizando, podemos afirmar:

■ **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e desde que aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional e em 2 turnos de votação (cf. art. 60, § 2.º, e art. 5.º, § 3.º):** equivalem a *emendas constitucionais* e, como visto, podem ser objeto de controle de constitucionalidade;

■ **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pela regra anterior à Reforma:** malgrado posicionamento pessoal deste autor já exposto, de acordo com a jurisprudência do STF,

guardam estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias** e, portanto, podem ser objeto de controle de constitucionalidade;

■ **tese da supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos (Gilmar Mendes)**: embora tenham o condão de “paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante” (voto no RE 466.343), podem sofrer controle de constitucionalidade, já que devem respeito ao princípio da supremacia da Constituição;

tratados e convenções internacionais de outra natureza: podem ser objeto de controle e têm força de lei ordinária.

O STF, por 5 x 4, em **03.12.2008**, no julgamento do **RE 466.343**, decidiu que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se não incorporados na forma do art. 5.º, § 3.º (quando teriam natureza de norma constitucional), têm natureza de normas **supralegais**, paralisando, assim, a eficácia de todo o ordenamento infraconstitucional em sentido contrário. [123](#)

Dessa forma, como diversos documentos internacionais de que o Brasil é signatário não mais admitem a prisão do depositário infiel (por exemplo, o art. 7.º, § 7.º, do *Pacto de São José da Costa Rica*, o art. 11 do *Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos*, a *Declaração Americana dos Direitos da Pessoa Humana*), a única modalidade de prisão civil a prevalecer na realidade brasileira é a do devedor de alimentos.

Com o máximo respeito, acompanhamos a divergência na linha do bem fundamentado voto do Min. Celso de Mello (natureza constitucional em razão da matéria, ampliando o conceito de “bloco de constitucionalidade” — cf. *item 6.7.1.3*).

Ademais, não conseguimos sustentar a manutenção de um documento que o STF declara acima da lei, mas abaixo da Constituição, contrariando o texto expresso que ainda persiste, no caso, o art. 5.º, LXVII.

Finalmente, entendemos prevalecer a afirmação exarada por Araujo e Nunes Júnior em relação à regra anterior, qual seja, a de que “o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto legislativo que ratifica um tratado internacional

não torna o ajuste internacional nulo, mas apenas exclui o Brasil de seu cumprimento, sujeitando-o, no entanto, a sanções internacionais decorrentes do descumprimento”.[124](#)

De qualquer maneira, apesar dessas considerações doutrinárias, o STF, na prática, não vem aceitando mais a prisão civil do depositário infiel, entendimento este, agora, materializado na **SV 25/2009** (DJE de 23.12.2009): “é **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

■ 6.7.1.2.8. Normas constitucionais originárias

Já observamos, ao tratar do poder constituinte, que as normas constitucionais fruto do trabalho do poder constituinte originário serão sempre constitucionais, não se podendo falar em controle de sua constitucionalidade. Os aparentes conflitos devem ser harmonizados por meio da atividade interpretativa, de forma sistêmica.

Quanto ao trabalho dos poderes derivados, como visto, pode ser declarado inconstitucional, uma vez que referido poder é condicionado aos limites e parâmetros impostos pelo originário.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF: “Ação direta de inconstitucionalidade. ADI. Inadmissibilidade. Art. 14, § 4.º, da CF. Norma constitucional originária. Objeto nomológico insuscetível de controle de constitucionalidade. **Princípio da unidade hierárquico-normativa e caráter rígido** da Constituição brasileira. Doutrina. Precedentes. Carência da ação. Inépcia reconhecida. Indeferimento da petição inicial. Agravo improvido. **Não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário**” (ADI 4.097-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08.10.2008, DJE de 07.11.2008).

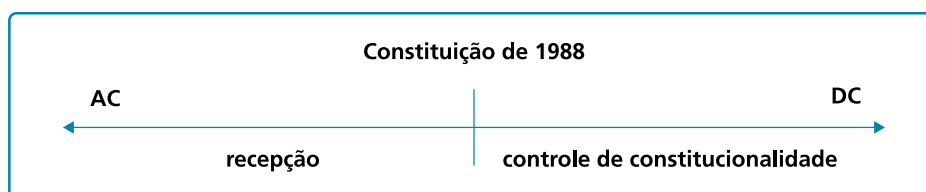
Apesar dessa **posição firme do STF** (a ser adotada em fases preambulares), em eventual discussão em banca de concurso,[125](#) é interessante que o ilustre candidato proponha uma releitura desse entendimento, especialmente diante dos **grandes princípios do bem comum, do direito natural, da moral e da**

razão, afastando-se a perspectiva rígida de uma “onipotência do poder constituinte” e na linha de consagração do princípio da proibição do retrocesso em relação aos direitos fundamentais. [126](#)

■ 6.7.1.2.9. O fenômeno da recepção

Em anotação ao regimento interno do STF (fonte *Internet*), lembrou-se o entendimento de que não cabe ADI para questionar validade de lei revogada na vigência de regime constitucional anterior. [127](#) Então, como deverá ser a verificação da constitucionalidade de lei ou ato normativo anterior à Constituição?

Como dissemos, todo ato normativo anterior à Constituição (“AC”) não pode ser objeto de controle. O que se verifica é se foi ou não **recepção** pelo novo ordenamento jurídico. Quando for compatível, será recebido, **recepção**. Quando não, não será **recepção** e, portanto, será **revogado** pela nova ordem, **não se podendo falar em inconstitucionalidade superveniente**. [128](#) Assim, somente os atos editados depois da constituição (“DC”) é que poderão ser questionados perante o STF, através do controle de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade). Vejamos o esquema:



Para maior entendimento do tema, confrontar o por nós exposto (*item 6.7.3*) sobre o fenômeno da recepção com a **arguição de descumprimento de preceito fundamental**, estabelecida no art. 102, § 1.º, da CF/88, regulamentada pela Lei n. 9.882/99, que permitiu o controle de atos normativos anteriores à Constituição (AC).

Resta saber se o STF entende ser possível a **modulação dos efeitos** da decisão em sede de declaração de não recepção da lei pré-constitucional pela norma constitucional superveniente, aplicando-se, por analogia, o art. 27 da Lei

n. 9.868/99.

Em alguns julgados que encontramos, na relatoria do Min. Celso de Mello, **não** foi admitida a modulação dos efeitos (cf. RE-AgR 353.508, j. 15.07.2007). **Contudo**, em divergência, o Min. Gilmar Mendes consignou a sua posição como sendo perfeitamente possível. Nesse caso, cf. AI 582.280 AgR, voto do Min. Celso de Mello, j. 12.09.2006, *DJ* de 06.11.2006 — íntegra do voto no *Inf.* 442/STF.

Parece-nos com razão o Min. Gilmar Mendes, até porque a Corte já admitiu a teoria da **lei ainda constitucional** no caso da ação civil *ex delicto*, que será analisada no *item* 6.7.1.6.1.2.

Em momento seguinte, devemos registrar, superando o entendimento anterior (vamos acompanhar se esse novo posicionamento vai se firmar na nova composição do STF — *matéria pendente*), a Corte reconheceu, expressamente, a possibilidade de **modulação** dos **efeitos de não recepção** de ato normativo editado antes de 1988 (cf. **RE 600.885**, j. 09.02.2011 — cf. *item* 13.6.3).

■ 6.7.1.2.10. *Atos estatais de efeitos concretos e atos estatais de efeitos concretos editados sob a forma de lei (exclusivamente formal)*

De modo geral, o STF afirma que, em razão da inexistência de densidade jurídico-material (densidade normativa), os **atos estatais de efeitos concretos** não estão sujeitos ao controle abstrato de constitucionalidade (STF, *RTJ* 154/432), na medida em que a ação direta de inconstitucionalidade não constitui sucedâneo da ação popular constitucional.

Assim, em um momento inicial, o STF passou a decidir no sentido de não se conhecer “... de ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos de efeitos concretos”. No caso, tratava-se da Lei n. 11.744/2002, do Estado do Rio Grande do Sul, que declarava como bens integrantes do patrimônio cultural e histórico estadual o prédio e a destinação do Quartel General da Brigada Militar em Porto Alegre (ADI 2.686-RS, Rel. Min. Celso de Mello, 03.10.2002, *Inf.* 284/STF).

A Corte mantinha o entendimento de que, “... só constitui ato normativo idôneo a submeter-se ao controle abstrato da ação direta aquele dotado de um coeficiente mínimo de **abstração** ou, pelo menos, de **generalidade**. Precedentes (v.g. ADI 767, Rezek, de 26.08.92, *RTJ* 146/483; ADI 842, Celso, *DJ* 14.05.93)” (ADI 1.937-MC/QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.06.2007, *DJ* de 31.08.2007).

CUIDADO: o STF, contudo, **modificou** o seu posicionamento. Trata-se de votação bastante apertada e em sede de **medida cautelar** (e por isso temos de acompanhar mais essa evolução da jurisprudência) que distingue o **ato de efeito concreto editado pelo Poder Público sob a forma de lei** do **ato de efeito concreto não editado sob a forma de lei**.

Portanto, mesmo que de efeito concreto, se o ato do Poder Público for materializado por **lei** (ou medida provisória, no caso a que **abre créditos extraordinários**, cf. *item 9.14.4.7*), poderá ser objeto do controle abstrato.

O STF, **modificando o seu entendimento**, destacou que “essas leis formais decorreriam ou da vontade do legislador ou do próprio constituinte, que exigiria que certos atos, **mesmo que de efeito concreto**, fossem **editados sob a forma de lei**. Assim, se a Constituição submeteu a lei ao processo de controle abstrato, meio próprio de inovação na ordem jurídica e instrumento adequado de concretização da ordem constitucional, **não seria admissível que o intérprete debilitasse essa garantia constitucional**, isentando um grande número de atos aprovados sob a forma de lei do controle abstrato de normas e, talvez, de qualquer forma de controle. Aduziu-se, ademais, **não haver razões de índole lógica ou jurídica contra a aferição da legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas**, e que estudos e análises no plano da teoria do direito apontariam a possibilidade tanto de se formular uma lei de efeito concreto de forma genérica e abstrata quanto de se apresentar como lei de efeito concreto regulação abrangente de um complexo mais ou menos amplo de situações. Concluiu-se que, em razão disso, o Supremo não teria andado bem ao reputar as leis de efeito concreto como inidôneas para o controle abstrato de normas” (**ADI 4.048-MC/DF**, Rel. Min. Gilmar Mendes, 17.04.2008).

Tendo em vista que a decisão foi tomada em **medida cautelar**, repetimos, resta aguardar como se dará a evolução da jurisprudência do STF. Para se ter uma ideia, o **PGR**, em seu parecer encaminhado à **ADI 4.047**, cujo objeto é a MP n. 409/2007, que abriu crédito extraordinário de R\$ 750 milhões em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, entendeu que o STF não pode analisar ato de efeito concreto, pedindo, em razão de a votação ter sido bastante apertada (**ADIs 4.048 e 4.049**, vide também *Inf. 527/STF*), uma **revisão da matéria**, retomando o entendimento anterior que não admitia ADI tendo por objeto ato de efeito concreto (cf. *Notícias STF*, 06.01.2009) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Em dois julgamentos já realizados (**ADI 4.048 e ADI 4.046**), houve entendimento no sentido da **prejudicialidade** das ações por **perda superveniente do objeto**, uma vez que, nos termos do art. 167, § 2.º, os créditos extraordinários abertos ou já tinham sido utilizados ou perderam a sua vigência. De todo modo, podemos afirmar essa tendência de mudança da orientação da Corte de acordo com os julgamentos proferidos nas cautelares.

■ 6.7.1.2.11. Ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida

O STF **não** admite a interposição de ADI para atacar lei ou ato normativo revogado ou de eficácia exaurida, na medida em que “não deve considerar, para efeito do contraste que lhe é inerente, a existência de paradigma revestido de valor meramente histórico”. [129](#)

Em razão de não caber a ADI e nem mesmo a ADC (pelos motivos expostos e em razão da ambivalência dessas ações), tendo em vista o princípio da subsidiariedade (art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 — cf. *item 6.7.3.6*), a Corte tem admitido o cabimento da **ADPF** contra ato normativo revogado ou com a sua eficácia exaurida (**ADPF 77-MC**, Rel. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, j. 19.11.2014, Plenário, *DJE* de 11.02.2015).

■ 6.7.1.2.12. Lei revogada ou que tenha perdido a sua vigência após a

propositura da ADI. O caso particular da fraude processual. Novas perspectivas: singularidades do caso (não prejudicialidade)

Nessa hipótese, estando em curso a ação e sobrevindo a revogação (total ou parcial) da lei ou ato normativo, assim como a perda de sua vigência (o que acontece com a medida provisória), ocorrerá, por regra, a prejudicialidade da ação, por “perda do objeto”. [130](#)

Isso porque, segundo entendimento do STF, a declaração em tese de lei ou ato normativo não mais existente transformaria a ADI em instrumento de proteção de **situações jurídicas pessoais e concretas** (STF, Pleno, ADI 737/DF, Rel. Min. Moreira Alves). Esses questionamentos deverão ser alegados na via ordinária, ou seja, por intermédio do controle difuso de constitucionalidade.

Nesse sentido, “a superveniente revogação — total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) — do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado” (ADI 2.010-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno). [131](#)

No entanto, em sentido contrário, destacamos importante voto do **Min. Gilmar Mendes**, relator, no julgamento de questão de ordem na ADI 1.244, **propondo** a “... **revisão da jurisprudência** do STF (...) para o fim de admitir o prosseguimento do controle abstrato nas hipóteses em que a norma atacada tenha perdido a vigência após o ajuizamento da ação, seja pela revogação, seja em razão do seu caráter temporário, restringindo o alcance dessa revisão às ações diretas pendentes de julgamento e às que vierem a ser ajuizadas. O Min. Gilmar Mendes, considerando que a remessa de controvérsia constitucional já instaurada perante o STF para as vias ordinárias é incompatível com os **princípios da máxima efetividade** e da **força normativa da Constituição**, salientou não estar demonstrada nenhuma razão de base constitucional a evidenciar que somente no âmbito do controle difuso seria possível a aferição da

constitucionalidade dos efeitos concretos de uma lei. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista da Ministra Ellen Gracie”. [132](#)

Mas **cuidado**, este não é, ainda, o entendimento pacificado no STF, que tem sustentado, em muitos precedentes e como regra, repita-se, a **prejudicialidade** da ação, conforme, por exemplo, no julgamento da ADI 514/PI, em **24.03.2008**, Rel. Min. Celso de Mello (*Inf. 499/STF*) e em tantos outros casos. [133](#)

Destacamos, contudo, três importantes precedentes nos quais o STF **superou** a preliminar de prejudicialidade:

- **ADI 3.232**: fraude processual;
- **ADI 3.306**: fraude processual;
- ADI 4.426**: singularidades do caso.

Na **ADI 3.232** (Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.08.2008, *DJE* de 03.10.2008), o STF afastou a prejudicialidade por se tratar de revogação da lei objetivo da ação apenas para frustrar o julgamento, especialmente por já estar pautada a ação. Entendeu o STF que se tratava de verdadeira **fraude processual** e, assim, superou a questão de ordem.

Nesse sentido, como sublinhou o Ministro Peluso, “... em conformidade com tese reafirmada em recente julgamento, de que foi Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito — que o fato de a lei objeto da impugnação ter sido revogada, não diria, no curso dos processos, mas já quase ao cabo deles, **não subtrai à Corte a jurisdição nem a competência para examinar a constitucionalidade da lei até então vigente e suas consequências jurídicas**, que, uma vez julgadas procedentes as três ações, não seriam, no caso, de pouca monta” (ADI 3.232, cf. *Inf. 515/STF*).

Nessa mesma linha, o julgamento da preliminar na **ADI 3.306** ao estabelecer que, “configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados” (ADI 3.306, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2011, Plenário, *DJE* de 07.06.2011).

Finalmente, no outro precedente, qual seja, no julgamento da **ADI 4.426**,

singularidades do caso justificaram o excepcional afastamento da jurisprudência atual que adota a regra da prejudicialidade da ação, na medida em que houve “**impugnação em tempo adequado** e a sua **inclusão em pauta antes do exaurimento da eficácia da lei temporária impugnada**, existindo a **possibilidade de haver efeitos em curso**” (ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.02.2011, Plenário, *DJE* de 18.05.2011. Cf. também a ADI 4.356).

Dessa forma, como se verifica na análise do item seguinte, o STF parece estar “cedendo” à proposta do Min. Gilmar Mendes de se rever o entendimento de prejudicialidade, especialmente em razão **da análise da situação concreta** (*vide* **ADI 2.158** e **ADI 2.189**). (*Na preparação para a prova, sugerimos que o nosso ilustre leitor certifique-se de não ter havido modificação do atual posicionamento do STF no sentido da prejudicialidade.*)

■ **6.7.1.2.13. Alteração do parâmetro constitucional invocado. Novo precedente na linha de não ocorrência de prejuízo desde que analisada a situação concreta. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria na hipótese de inadmitida constitucionalidade superveniente**

Prevalece o entendimento no STF de que, havendo alteração no **parâmetro constitucional invocado** (no caso, por emenda constitucional), e já proposta a ADI, esta deve ser julgada **prejudicada** em razão da perda superveniente de seu objeto (já que a emenda constitucional, segundo a Corte, revoga a lei infraconstitucional em sentido contrário e que era o objeto da ADI).

Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello aduz que “... a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o regime constitucional anterior, tem proclamado que tanto a superveniente **revogação global** da Constituição da República (*RTJ* 128/515, 130/68, 130/1002, 135/515 e 141/786) quanto a **posterior derrogação (ou alteração substancial) da norma constitucional** (*RTJ* 168/436, 169/834, 169/920, 171/114, 172/54-55 e 179/419; ADI 296/DF, 595/ES, 905/DF, 906/PR, 1.120/PA, 1.137/RS, 1.143/AP, 1.300/AP, 1.510/SC e 1.885-QO/DF), por afetarem o paradigma de confronto invocado no processo de controle concentrado de constitucionalidade, configuram hipóteses

caracterizadoras de **prejudicialidade** da ação direta ou da ação declaratória, em virtude da evidente perda de seu objeto...”.

Podemos citar dois exemplos nos quais se percebia essa orientação, ou seja, que a mudança de **paradigma** acarretava, por regra, a prejudicialidade da ADI previamente ajuizada:

a) revogação primitiva do art. 39, § 1.º, pela EC n. 19/98 — *RTJ* 172/789-90, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:

“... II. Controle direto de inconstitucionalidade: prejuízo. Julga-se prejudicada total ou parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade no ponto em que, depois de seu ajuizamento, emenda à Constituição haja ab-rogado ou derogado norma de Lei Fundamental que constituísse paradigma necessário à verificação da procedência ou improcedência dela ou de algum de seus fundamentos, respectivamente: orientação de aplicar-se no caso, no tocante à alegação de inconstitucionalidade material, dada a revogação primitiva do art. 39, § 1.º, CF/88, pela EC 19/98” (ADI 1.434/SP, Rel. Min. Sepúlveda, *DJ* de 25.02.2000).

b) alteração do art. 40, *caput*, pela EC n. 41/2003, agora permitindo a taxação dos inativos:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 3.310/99. Cobrança de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. EC 41/2003. Alteração substancial do Sistema Público de Previdência. Prejudicialidade. 1. Contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Norma editada em data posterior ao advento da EC 20/98. Inconstitucionalidade da lei estadual em face da norma constitucional vigente à época da propositura da ação. 2. Superveniência da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o sistema previdenciário. Prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de aferição da regra legal impugnada. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada” (ADI 2.197/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 02.04.2004, p. 8).

Nessas hipóteses (alteração do paradigma constitucional), na mesma linha do

voto do Ministro Gilmar Mendes (questão de ordem na ADI 1.244, *Inf. 305/STF*), que busca rever a jurisprudência já pacificada do STF em relação à superveniente revogação de lei objeto da ADI, entendíamos ser razoável a continuidade da ação para a fixação da amplitude dos efeitos produzidos, especialmente na hipótese de inconstitucionalidade do objeto da ação.

CUIDADO — mudança de entendimento pelo STF para se evitar a inadmitida constitucionalidade superveniente da lei objeto da ADI (15.09.2010).

Entretanto, no julgamento da questão de ordem na **ADI 2.158**, o STF rejeitou a preliminar de prejudicialidade, mesmo tendo havido a alteração no parâmetro de confronto.

No caso concreto, discutia-se lei do Estado do Paraná que, antes da novidade introduzida pela EC n. 41/2003, estabelecia a taxaço dos inativos.

Como se sabe, a possibilidade de taxaço dos inativos foi introduzida **somente** com o advento da EC n. 41/2003 (*Reforma da Previdência*), e não na redação original da Constituição.

Assim, antes da modificação introduzida pela EC n. 41/2003, nenhum ato normativo, mesmo na vigência das regras trazidas pela EC n. 20/98, poderia prescrever a taxaço dos inativos.

Por esse motivo, toda lei que eventualmente assim disciplinasse, como foi o caso do Paraná, conteria **vício congênito** de inconstitucionalidade e, portanto, teria “nascido morta”.

A partir do momento que a EC n. 41/2003 passou a admitir a taxaço dos inativos (anteriormente não admitida, já que inconstitucional), foi como se a referida lei, ainda no ordenamento, pudesse ser “recebida” pela nova emenda, já que com ela (a nova regra trazida por emenda) adequada.

Como, porém, o STF **não** admite o fenômeno da **constitucionalidade superveniente**, por esse motivo a referida lei, que nasceu inconstitucional, deve ser nulificada perante a regra da Constituição que vigorava à época de sua edição (**princípio da contemporaneidade**).

Dessa forma, examinando a situação do caso concreto, e **modificando o seu**

entendimento, o STF não admitiu o pedido de prejudicialidade, analisando a constitucionalidade da lei à luz da regra constitucional que à época vigorava (**ADI 2.158** e **ADI 2.189**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.09.2010, Plenário, *DJE* de 16.12.2010).

■ **6.7.1.2.14. Divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo**

O STF entendeu **não** caracterizar situação de controle de constitucionalidade, na medida em que a simples divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo não seria suficiente para configurar afronta à Constituição (STF, Pleno, ADI 1.096-4, medida liminar, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 1, de 22.09.1995, p. 30589).

■ **6.7.1.2.15. Respostas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral**

Julgou o STF não configurarem objeto de ADI as respostas emitidas pelo TSE às consultas que lhe forem endereçadas, na medida em que referidos atos não possuem “eficácia vinculativa aos demais órgãos do Poder Judiciário” (STF, ADI 1.805-MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, *Inf. 104/STF*), tratando-se de ato de caráter administrativo.

■ **6.7.1.2.16. Leis orçamentárias?**

De modo geral, o STF entendia que as leis orçamentárias, ou a lei de diretrizes orçamentárias, não poderiam ser objeto de controle, já que se tratava de **leis com efeito concreto, ato administrativo em sentido material**, vale dizer, **leis com objeto determinado e destinatário certo** (cf. *Inf. 99*, ADI(QO) 1.640; *Inf. 175/STF*, ADI 2.100).

Em uma jurisprudência inicial, o STF decidiu que, se demonstrado “um certo grau de abstração e generalidade” da lei, seria admitido o controle em abstrato mediante a ADI. Como exemplo citamos os *Informativos STF* ns. 255 e 333

(ADI 2.925), este último no qual se discutia a abstração da norma que tratava da “suplementação de crédito para reforço de dotações vinculadas aos recursos da CIDE-Combustíveis”.

Evoluindo a jurisprudência (cf. *itens 6.7.1.2.5 e 6.7.1.2.10*), o STF passou a admitir o controle de constitucionalidade das leis orçamentárias. Confira: “Controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias. **Revisão de jurisprudência**. O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, **independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade.** (...) Medida cautelar deferida. Suspensão da vigência da Lei n. 11.658/2008, desde a sua publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008” (ADI 4.048-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.05.2008, *DJE* de 22.08.2008). No mesmo sentido: ADI 4.049-MC, cf. *Inf. 527/STF*.

Isso porque a **lei orçamentária** é um ato de efeito concreto na aparência, já que, como decidido, para que seja executada, dependerá da edição de muitos outros atos, estes, sim, de efeito concreto.

Observamos que a **abertura de crédito extraordinário** pode, segundo o STF, ser comparada à lei orçamentária e, assim, mesmo que por MP, vir a ser o ato questionado por ADI (cf. ADI 4.048 e 4.049, *Infs. 502, 506 e 527/STF* e discussão da matéria no *item 9.14.4.7*).

Conforme alertado, considerando que a decisão foi tomada em **medida cautelar**, resta aguardar a evolução da jurisprudência do STF. Relembre-se que o **PGR**, em seu parecer encaminhado à **ADI 4.047**, entendeu que o STF não pode analisar ato de efeito concreto, pedindo, tendo em conta que a votação foi bastante apertada (**ADIs 4.048 e 4.049**, *vide também Inf. 527/STF*), uma **revisão da matéria**, retomando o entendimento anterior que não admitia ADI tendo por objeto ato de efeito concreto (cf. *Notícias STF*, 06.01.2009) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Cumprе repetir aqui que, em dois julgamentos já realizados (**ADI 4.048** e

ADI 4.046), entendeu-se pela **prejudicialidade** das ações por **perda superveniente do objeto**. Isso porque, nos termos do art. 167, § 2.º, os créditos extraordinários abertos ou já tinham sido utilizados ou perderam a sua vigência. Assim, podemos afirmar essa tendência de mudança da orientação da Corte de acordo com os julgamentos proferidos nas cautelares.

■ 6.7.1.2.17. Resoluções do CNJ e do CNMP

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (art. 103-B, § 4.º), bem como o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) (art. 103-A, § 2.º), introduzidos pela *Reforma do Poder Judiciário* (EC n. 45/2004), no exercício de suas atribuições constitucionais e regimentais, podem elaborar **resoluções**.

Algumas dessas resoluções, segundo o STF, são dotadas da qualidade da **generalidade**, **impessoalidade** e **abstração** (cf., por exemplo, ambas do CNJ, a *Res. n. 7/2005* — que proíbe o nepotismo — e a *Res. n. 175/2013* — que veda às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo).

Nessas situações, o STF vem reconhecendo a natureza jurídica de **ato normativo primário** dessas resoluções, que inovam a ordem jurídica a partir de parâmetros constitucionais e, assim, permitem o controle concentrado por meio de ADI genérica. [134](#)

Veda-se, portanto, de acordo com a jurisprudência da Corte, a impetração de **mandado de segurança** para o questionamento desses atos normativos primários, com fundamento na **S. 266/STF**, por se tratar de “lei” em tese.

■ 6.7.1.2.18. Ato administrativo normativo genérico (ADI 3.202 — agravo regimental em processo administrativo)

O tema discutido nos autos da **ADI 3.202** (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.02.2014, Plenário, *DJE* de 21.05.2014) é bastante interessante. Diversos

servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte conseguiram, quer administrativa quer judicialmente, determinada gratificação por trabalho científico, técnico ou administrativo que exija conhecimento especial.

Partindo desses precedentes paradigmáticos, com base no princípio da isonomia, dois servidores fizeram pedido administrativo perante o Tribunal de Justiça objetivando a mesma gratificação, já que estavam em situação idêntica àquela das pessoas que tiveram o seu reconhecimento.

Inicialmente, o pedido foi indeferido. Interposto agravo regimental no Processo Administrativo n. 102.138/2003, o Plenário do TJRN deu provimento para conferir aos agravantes (2 servidores) a gratificação e, **extrapolando** o pedido, também com base no princípio da isonomia, “determinou a **extensão** desse benefício aos servidores que se encontravam em níveis correspondentes àqueles que obtiveram idêntica vantagem”.

Então foi posta a **questão preliminar**: a decisão proferida no agravo regimental no referido processo administrativo que **estendeu os efeitos** para todos os servidores em situação idêntica pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade por meio de ADI genérica? Estamos diante de ato administrativo normativo genérico?

A Corte, por 9 x 1, entendeu que sim e, portanto, a **extensão** poderia ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade por meio da ADI genérica, já que, como bem colocou o Min. Celso de Mello, trata-se de “ato impregnado de suficiente densidade normativa, considerados os aspectos de generalidade abstrata e de impessoalidade que o tipificam” (fls. 32 do acórdão).

■ 6.7.1.2.19. ADI “**versus**” políticas públicas? A teoria da “reserva do possível”

Conforme a ementa da ADPF 45 (de indispensável leitura): “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A questão da legitimidade constitucional do **controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de**

implementação de políticas públicas, quando **configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional** atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da **‘reserva do possível’**. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do **‘mínimo existencial’**. Viabilidade instrumental da arguição de descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração)” (*Inf. 345/STF*).

Há de se verificar, portanto, no caso concreto, a “razoabilidade da pretensão” e a “disponibilidade financeira” do Estado para a implementação da política pública via controle do STF. Assim, a violação aos direitos mínimos tem de ser **evidente e arbitrária**, como o desvio do dinheiro destinado ao ensino e à saúde (art. 34, VII, “e”) para a construção de uma obra de embelezamento; ou, ainda, o veto do Executivo a dispositivo da *lei orçamentária anual* que destine dinheiro do fundo de erradicação da pobreza proveniente da extinta CPMF para finalidade distinta.

■ **6.7.1.3. Elementos essenciais do controle de constitucionalidade: a) elemento conceitual (o conceito de “bloco de constitucionalidade”); b) elemento temporal**

O tema proposto foi muito bem explorado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da *ADI 595-ES* (*Inf. 258/STF*) e de indispensável leitura pelo candidato vitorioso!

No referido julgamento fixa-se, com precisão, a ideia de dois **elementos essenciais** para se falar em controle de constitucionalidade.

O primeiro, para o ilustre Ministro, denominado **elemento conceitual**, “... consiste na determinação da própria ideia de Constituição e na definição das premissas jurídicas, políticas e ideológicas que lhe dão consistência”. O outro, “o **elemento temporal**, cuja configuração torna imprescindível constatar se o

padrão de confronto, alegadamente desrespeitado, ainda vige, pois, sem a sua concomitante existência, descaracterizar-se-á o fator de contemporaneidade, necessário à verificação desse requisito”.

O *elemento temporal* já foi analisado tanto no tocante à revogação de lei (cuja constitucionalidade está sendo questionada, qual seja, o objeto da ação), como na hipótese de alteração do parâmetro constitucional invocado (em relação ao qual se afere a compatibilidade vertical) (cf. *itens 6.7.1.2.12 e 6.7.1.2.13*).

Em relação ao **elemento conceitual**, a ideia é identificar o que deve ser entendido como parâmetro de constitucionalidade. Trata-se de nítido processo de aferição da *compatibilidade vertical* das normas inferiores em relação ao que foi considerado como “modelo constitucional” (**vínculo de ordem jurídica**, tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição — **paradigma de confronto**).

Nesse sentido, duas posições podem ser encontradas. Uma **ampliativa** (englobando não somente as normas formalmente constitucionais como, também, os princípios não escritos da “ordem constitucional global” e, inclusive, valores suprapositivos) e outra **restritiva** (o parâmetro seriam somente as normas e princípios expressos da Constituição escrita e positivada).

Quanto à perspectiva ampliativa, o Ministro Celso de Mello (*Inf. 258/STF*) vislumbra possam ser “... considerados não apenas os preceitos de índole positiva, expressamente proclamados em documento formal (que consubstancia o texto escrito da Constituição), mas, sobretudo, que sejam havidos, igualmente, por relevantes, em face de sua transcendência mesma, os valores de caráter suprapositivo, os princípios cujas raízes mergulham no direito natural e o próprio espírito que informa e dá sentido à Lei Fundamental do Estado”.

E completa: “não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, certa vez, e para além de uma perspectiva meramente reducionista, veio a proclamar — distanciando-se, então, das exigências inerentes ao positivismo jurídico — que a Constituição da República, muito mais do que o conjunto de normas e princípios nela formalmente positivados, há de ser também entendida em função do próprio espírito que a anima, afastando-se, desse modo, de uma concepção

impregnada de evidente minimalismo conceitual (*RTJ* 71/289, 292 e 77/657)”.

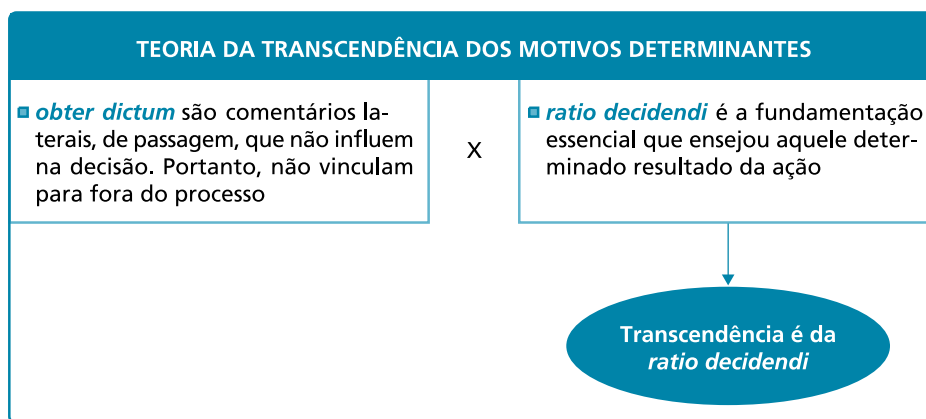
Diante de todo o exposto, busca-se fixar, com clareza para o direito brasileiro, o conceito de **bloco de constitucionalidade**, qual seja, o que deverá servir de parâmetro para que se possa realizar a confrontação e aferir a constitucionalidade. [135](#)

A tendência ampliativa parece-nos **tímida** na jurisprudência brasileira, que adotou, do ponto de vista jurídico, a ideia de **supremacia formal**, apoiada no conceito de **rigidez constitucional** e na consequente obediência aos **princípios e preceitos decorrentes da Constituição**.

Nesse sentido, Bernardes observa que “... no direito brasileiro prevalece a restrição do parâmetro direto de controle — que aqui poderia ser chamado de *bloco de constitucionalidade em sentido estrito* — às normas contidas, ainda que não expressamente, em texto constitucional (normas formalmente constitucionais)”. [136](#)

Com o advento da **EC n. 45/2004** pode-se asseverar ter havido ampliação do “bloco de constitucionalidade” na medida em que se passa a ter um novo parâmetro (*norma formal e materialmente constitucional*) — os **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos** que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, [137](#) nos termos do art. 5.º, § 3.º, da CF/88.

■ **6.7.1.4. Teoria da transcendência dos motivos determinantes (efeitos irradiantes ou transbordantes?) (“Ratio decidendi” — “holding” versus “obiter dictum” — “dictum”)**



O STF vinha atribuindo efeito vinculante não somente ao dispositivo da sentença, mas, também, aos **fundamentos determinantes da decisão**.

Falava-se, então, em **transcendência dos motivos determinantes**, ou **efeitos irradiantes** ou **transbordantes dos motivos determinantes**.

Há de se observar, inicialmente, a distinção entre *ratio decidendi* e *obter dictum*.

Obter dictum (“coisa dita de passagem”) ou simplesmente *dictum* são comentários laterais, que não influem na decisão, sendo perfeitamente dispensáveis. Portanto, aceita a “**teoria do transbordamento**”, não sealaria em irradiação de *obter dictum*, com efeito vinculante, para fora do processo. Por outro lado, a *ratio decidendi*, sendo *holding* a denominação mais usual na experiência norte-americana,¹³⁸ é a fundamentação essencial que ensejou aquele determinado resultado da ação. Nessa hipótese, aceita a “teoria dos efeitos irradiantes”, a “razão da decisão” passaria a vincular outros julgamentos.

Como exemplo, no julgamento da ADI 3.345/DF, que declarou constitucional a Resolução do TSE que reduziu o número de vereadores de todo o País, o STF entendeu que a Suprema Corte conferiu “... efeito transcendente aos próprios motivos determinantes que deram suporte ao julgamento plenário do RE 197.917”.

Sobre a **transcendência dos motivos determinantes**, cf. Rcl 2.986 MC/SE (*Inf. 379/STF*) e Rcl 2.475 (*Inf. 335/STF*), com os comentários já feitos em relação ao controle difuso (cf. *item 6.6.5*).

CUIDADO: no julgamento da **Rcl 10.604** (08.09.2010), o STF **afastou** a

técnica do **transbordamento dos motivos determinantes**.

Em referido julgado, há referência à questão de ordem na **Rcl 4.219**, na qual se sinaliza a manifestação de 6 Ministros **contra** a teoria da transcendência.

Trata-se de verdadeira **jurisprudência defensiva**, no sentido de se evitar o número crescente de reclamações.

Com o máximo respeito, **não parece razoável** desprezar a teoria da transcendência no **controle concentrado**, já que a **tese jurídica** terá sido resolvida e o dispositivo deve ser lido, em uma perspectiva moderna, à luz da fundamentação (lembrando que somos contra a teoria da transcendência no controle difuso, cf. *item 6.6.5*).

De qualquer forma (e teremos que acompanhar essa *tendência de não aceitação da teoria do transbordamento* — **matéria pendente** de apreciação específica pelo Plenário em sua atual composição), nas palavras do relator Min. Ayres Britto, “... no julgamento da Rcl 4.219, esta nossa Corte retomou a discussão quanto à aplicabilidade dessa mesma teoria da ‘transcendência dos motivos determinantes’, oportunidade em que deixei registrado que tal aplicabilidade implica prestígio máximo ao órgão de cúpula do Poder Judiciário e **desprestígio igualmente superlativo aos órgãos da judicatura de base**, o que se contrapõe à essência mesma do **regime democrático**, que segue lógica inversa: a lógica da desconcentração do poder decisório. Sabido que democracia é movimento ascendente do poder estatal, na medida em que opera de baixo para cima, e nunca de cima para baixo. No mesmo sentido, cinco ministros da Casa esposaram entendimento rechaçante da adoção do transbordamento operacional da reclamação, ora pretendido. Sem falar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já rejeitou, em diversas oportunidades, a tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes das suas decisões (cf. Rcl 2.475-AgR, da relatoria do ministro Carlos Velloso; Rcl 2.990-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; Rcl 4.448-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 3.014, de minha própria relatoria)” (Min. Ayres Britto, 08.09.2010). (Cf., ainda, nesse mesmo sentido, decisão da 1.^a T. do STF, **Rcl 11.477-AgR**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.05.2012, *Inf. 668/STF*.)

■ **6.7.1.5. Teoria da inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”, ou inconstitucionalidade consequencial, ou inconstitucionalidade consequente ou derivada, ou “inconstitucionalidade por reverberação normativa”**

Esse importante tema aparece intimamente ligado aos limites objetivos da coisa julgada e à produção dos efeitos *erga omnes*. [139](#)

Pela referida teoria da **inconstitucionalidade por “arrastamento”** ou **“atração”**, ou **“inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”**, ou **“inconstitucionalidade por reverberação normativa”**, se em determinado processo de controle concentrado de constitucionalidade for julgada inconstitucional a norma principal, em futuro processo, outra norma dependente daquela que foi declarada inconstitucional em processo anterior — tendo em vista a **relação de instrumentalidade** que entre elas existe — também estará eivada pelo vício de inconstitucionalidade “consequente”, ou por “arrastamento” ou “atração”.

Poder-se-ia pensar, nesse ponto, que a consequência prática da coisa julgada material, que se projeta para fora do processo, impediria não só que a mesma pretensão fosse julgada novamente, como também, sob essa interessante perspectiva, que a norma consequente e dependente ficasse vinculada tanto ao dispositivo da sentença (principal) quanto à *ratio decidendi*, invocando, aqui, a “teoria dos motivos determinantes”.

Esses dois temas no âmbito do controle de constitucionalidade vislumbram uma perspectiva *erga omnes* para os limites objetivos da coisa julgada, em importante avanço em relação à teoria clássica. [140](#)

Naturalmente, essa técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pode ser aplicada tanto em processos distintos como em um mesmo processo, situação que vem sendo verificada com mais frequência na jurisprudência do STF.

Ou seja, já na própria decisão, a Corte define quais normas são atingidas, e no dispositivo, por **“arrastamento”**, também reconhece a **invalidade** das

normas que estão “**contaminadas**”, mesmo na hipótese de não haver pedido expresso na petição inicial.

Essa “contaminação”, ou, mais tecnicamente, perda de validade, pode ser reconhecida, também, em relação a decreto que se fundava em lei declarada inconstitucional. Então, o STF vem falando em inconstitucionalidade por arrastamento do decreto que se fundava na lei (cf., por exemplo, ADI 2.995/PE, Rel. Min. Celso de Mello, 13.12.2006).¹⁴¹ Interessante observar que o decreto regulamentar, por si, conforme visto, não pode ser isoladamente objeto de ADI, na medida em que deve ser confrontado com a lei (que regula), e não diretamente perante a Constituição. A *crise é de legalidade* e apenas de *modo indireto, reflexo* ou *obliquo* é que poderia haver violação da Constituição. Pela técnica do arrastamento, contudo, a declaração de sua invalidade dar-se-á no julgamento da própria ADI.

Em outro julgado, declarada a inconstitucionalidade de um dispositivo, os outros que estavam na mesma lei e que tinham relação com aquele nulificado, por **perderem a sua razão de ser**, foram também declarados inconstitucionais, de acordo com aquilo que o Min. Ayres Britto denominou **inconstitucionalidade por reverberação normativa** (cf. voto do Min. Ayres Britto proferido na **ADI 1.923** — *Inf. 622/STF* — e na **ADI 4.357** — *Inf. 643/STF*).

Como anotam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, “com efeito, se as normas legais guardam interconexão e mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, formando-se uma incindível unidade estrutural, não poderá o Poder Judiciário proclamar a inconstitucionalidade de apenas algumas das disposições, mantendo as outras no ordenamento jurídico, sob pena de redundar na desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas”.¹⁴²

Essa reverberação, sem dúvida, deve ser reconhecida entre normas interconectadas por uma relação hierárquica, observando-se, assim, um **arrastamento no plano vertical**. Dessa forma, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma de determinada Constituição estadual implicaria o reconhecimento da perda de validade das normas hierarquicamente

inferiores e que se fundavam naquele dispositivo.

O instituto do “arrastamento” é, sem dúvida, exceção à regra de que o juiz deve ater-se aos limites da lide fixados na exordial, especialmente em virtude da correlação, conexão ou interdependência dos dispositivos legais e do caráter político do controle de constitucionalidade realizado pelo STF.¹⁴³ Estamos diante de inegável revisitação da *regra da congruência* (ou *correlação*) entre o pedido e a sentença (arts. 128 e 460 do CPC/73 — arts. 141 e 492, CPC/2015), decorrentes do *princípio dispositivo* e que devem ser analisados sob esse novo e particular aspecto do processo objetivo.

■ **6.7.1.6. Lei “ainda constitucional”, ou “inconstitucionalidade progressiva”, ou “declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade”**

■ **6.7.1.6.1. A instituição da Defensoria Pública pela CF/88 e a sua potencialização pela EC n. 80/2014**

O art. 5.º, LXXIV, da CF/88 dispõe que o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Esse direito e garantia fundamental instrumentaliza-se por meio da **Defensoria Pública**, instituída pela CF/88, **amplificada** pela **EC n. 80/2014** (art. 134, *caput*) e organizada em **carreira própria** nos seguintes termos: instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal.

Pelo fato de ter sido instituída pela Constituição de 1988, a Defensoria Pública tem de ser **efetivamente instalada**, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou distrital, o que leva certo tempo.

Esse comando que se extrai desde a sua previsão no texto de 1988 é fortalecido pela **EC n. 80/2014**. Ao acrescentar o art. 98 ao ADCT e prescrever que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população, **fixa-se** o prazo de **8 anos** para que a União, os Estados e o Distrito Federal passem a contar com defensores públicos em **todas** as unidades jurisdicionais.

Durante o decurso desse prazo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, **prioritariamente**, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

O que fazer, então, durante esse período de transição, necessário para a efetiva instalação da Defensoria Pública?

Para analisar o tema, trouxeamos duas questões práticas já enfrentadas pelo STF: **a)** a previsão de prazo em dobro para a Defensoria Pública no processo penal; **b)** a ação civil *ex delicto* ajuizada pelo MP depois do advento da CF/88.

■ 6.7.1.6.1.1. A questão do “prazo em dobro” para a Defensoria Pública no processo penal — rejeição de inconstitucionalidade “*rebus sic stantibus*”

Nos termos dos arts. 44, I, 89, I, e 128, I, da LC n. 80/94, é prerrogativa dos membros da Defensoria Pública receber **intimação pessoal** em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em **dobro todos os prazos**. [144](#)

Em relação ao **processo civil**, a regra não sofreu nenhuma repreensão por parte do STF, até porque há equivalente para o MP (e a Fazenda Pública), conforme o art. 188 do CPC/73 (cf. arts. 180, 183 e 186, CPC/2015).

No tocante ao **processo penal**, contudo, na medida em que o MP não goza dessa prerrogativa de prazo em dobro, questionou-se se, de fato, a regra poderia ser estabelecida para a Defensoria Pública quando atua como defensora em acusação formulada pelo MP, especialmente em relação ao princípio da isonomia e ao do devido processo legal.

O STF, ao analisar o tema do **prazo em dobro para o processo penal**,

entendeu que referida regra é constitucional até que a Defensoria Pública efetivamente se instale.

Assim, o prazo em dobro para o processo penal só valerá enquanto a Defensoria Pública ainda não estiver eficazmente organizada. Quando isso se verificar, a regra tornar-se-á **inconstitucional**. Trata-se, portanto, de **norma em trânsito para a inconstitucionalidade**.

Nesse sentido, confira o precedente **HC 70.514**, j. 23.03.1994: “EMENTA: Direito Constitucional e **Processual Penal**. Defensores Públicos: prazo em dobro para interposição de recursos (§ 5.º do art. 1.º da Lei n. 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 08.11.1989). Constitucionalidade. ‘Habeas Corpus’. Nulidades. Intimação pessoal dos Defensores Públicos e prazo em dobro para interposição de recursos. 1. Não é de ser reconhecida a inconstitucionalidade do § 5.º do art. 1.º da Lei n. 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 08.11.1989, no ponto em que confere **prazo em dobro**, para recurso, às Defensorias Públicas, **ao menos até que sua organização, nos Estados, alcance o nível de organização do respectivo Ministério Público, que é a parte adversa, como órgão de acusação, no processo da ação penal pública...**” (grifamos).

Interessante, também, o voto do Ministro Moreira Alves, que pedimos vênua para transcrever: “a única justificativa que encontro para esse tratamento desigual em favor da Defensoria Pública em face do Ministério Público é a de caráter temporário: a circunstância de as Defensorias Públicas ainda não estarem, por sua recente implantação, devidamente aparelhadas como se acha o Ministério Público. Por isso, para casos como este, parece-me deva adotar-se a construção da Corte Constitucional alemã no sentido de considerar que uma lei, em virtude das circunstâncias de fato, pode vir a ser inconstitucional, não o sendo, porém, enquanto essas circunstâncias de fato não se apresentarem com a intensidade necessária para que se tornem inconstitucionais. Assim, **a lei em causa será constitucional enquanto a Defensoria Pública, concretamente, não estiver organizada com a estrutura que lhe possibilite atuar em posição de igualdade com o Ministério Público, tornando-se**

inconstitucional, porém, quando essa circunstância de fato não mais se verificar” (grifamos).

■ **6.7.1.6.1.2. Ação civil “ex delicto” ajuizada pelo MP — art. 68 do CPP (lei ainda constitucional e em trânsito para revogação por não recepção)**

O art. 68 do CPP estabelece: “quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1.º e 2.º), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público”.

Retorna-se então à dúvida: o art. 68 do CPP previu a ação civil *ex delicto*, que deve ser ajuizada pelo MP. Essa atribuição, no entanto, a partir de 1988, passou a ser da Defensoria Pública, seja em razão de sua previsão constitucional (art. 134), seja em razão da regra contida no art. 129, IX, que autoriza o MP a exercer outras funções que lhe forem conferidas, **desde que compatíveis com a sua finalidade**, vedando, assim, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Então, pelo exposto, o art. 68 do CPP teria sido **revogado**, por não recepção, pelo texto de 1988.

A Defensoria Pública, por sua vez, não se instalou efetivamente logo após a promulgação da CF/88. Para se ter um argumento, só a partir da *Reforma do Judiciário* (**EC n. 45/2004**) é que a Defensoria Pública Estadual passou a ter autonomia funcional e administrativa, e a autonomia da Defensoria Pública do DF veio a ser reconhecida apenas na **EC n. 69/2012**, já que antes organizada e mantida pela União. Ainda, foi somente com a **EC n. 74/2013** que a Defensoria Pública da União, por sua vez, passou a ter autonomia (art. 134, § 3.º, CF/88) e, finalmente, com a **EC n. 80/2014**, houve sensível potencialização da instituição, fixando-se prazo para sua efetiva instalação nos termos do art. 98 do ADCT (cf. *item 12.6*).

Portanto, vem o STF entendendo, de maneira acertada, que o art. 68 do CPP é uma lei **ainda constitucional** e que está **em trânsito, progressivamente**,

para a “**inconstitucionalidade**”, à medida que as Defensorias Públicas forem sendo, **efetiva e eficazmente**, instaladas.

Apenas deixamos um alerta de que a terminologia utilizada pela Suprema Corte não é a mais adequada, uma vez que, por se tratar de ato editado antes de 1988 (art. 68 do CPP), referido dispositivo seria revogado por não recepção. Trata-se, assim, em razão das circunstâncias, de reconhecida modulação do momento de revogação do ato, e por isso a denominamos *lei ainda constitucional e em trânsito para revogação por não recepção*.

A técnica da “lei ainda constitucional”, conforme noticiado, está consagrada no STF:¹⁴⁵ “Ministério Público: legitimação para promoção, no juízo cível, do ressarcimento do dano resultante de crime, pobre o titular do direito à reparação: C. Pr. Pen., art. 68, ainda constitucional (cf. RE 135.328): **processo de inconstitucionalização das leis**. 1. A alternativa radical da jurisdição constitucional ortodoxa, entre a constitucionalidade plena e a declaração de inconstitucionalidade ou revogação por inconstitucionalidade da lei, com fulminante eficácia *ex tunc*, faz abstração da evidência de que **a implementação de uma nova ordem constitucional não é um fato instantâneo**, mas um processo no qual a possibilidade de realização da norma da Constituição — ainda quando teoricamente não se cuide de preceito de eficácia limitada — subordina-se muitas vezes a alterações da realidade fática que a viabilizem. 2. No contexto da Constituição de 1988, a atribuição anteriormente dada ao Ministério Público pelo art. 68 C. Pr. Penal — constituindo modalidade de assistência judiciária — deve reputar-se transferida para a Defensoria Pública: essa, porém, para esse fim, só se pode considerar existente, onde e quando **organizada, de direito e de fato, nos moldes do art. 134** da própria Constituição e da lei complementar por ela ordenada: até que — na União ou em cada Estado considerado — se implemente essa condição de viabilização da cogitada transferência constitucional de atribuições, o art. 68 C. Pr. Pen. será considerado **ainda vigente**: é o caso do Estado de São Paulo, como decidiu o plenário no RE 135328” (RE 147.776/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.^a Turma, RTJ 175/309-310).

■ **6.7.1.6.2. Procedimento de aprovação das medidas provisórias: apreciação pela comissão mista nos termos do art. 62, § 9.º, da CF/88. Arts. 5.º, “caput”, e 6.º, “caput”, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN**

Conforme já estudamos no *item* 6.6.5.3, a Res. n. 1/2002-CN, integrante do *Regimento Comum*, dispôs sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, de medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.

Os seus arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, permitiam que o parecer da comissão mista fosse emitido por relator ou relator revisor designado.

Esse procedimento vinha sendo adotado na apreciação de várias medidas provisórias, até como um mecanismo de funcionalidade do procedimento.

Segundo o Min. Cezar Peluso, no julgamento da **ADI 4.029** (08.03.2012), **vencido** nesse ponto, não se percebia qualquer “coisa anômala ou atípica” na fixação de prazo para atuação da comissão, até porque, “doutro modo, pensando-se que o Congresso não possa fazê-lo, temos o quê? Temos que essa comissão não se sentirá obrigada, em nenhum instante, a manifestar-se, e vai se escoar o prazo após o qual a medida provisória perde a eficácia. Noutras palavras, é **método de operacionalidade do próprio Legislativo**. Se o Legislativo não estabelece esse prazo, a comissão evidentemente não se sentirá de nenhum modo movida a exercer a competência que a Constituição lhe atribui” (fls. 69).

Esse, contudo, não foi o entendimento que prevaleceu diante da regra contida no **art. 62, § 9.º, da CF/88**, que deve ser interpretado restritivamente, pois, consoante observou o Min. Ayres Britto em seu voto, as medidas provisórias “investem o Presidente da República — vamos ficar no plano federal para facilitar o debate — num poder excepcional, numa competência excepcional de ser a fonte produtora de uma norma primária, inovadora, portanto, do ordenamento jurídico, logo abaixo da Constituição”.

Referido dispositivo constitucional estabelece ser atribuição da **comissão mista** de Deputados e Senadores **examinar** as medidas provisórias e sobre elas **emitir parecer**, de caráter **opinativo**, acrescente-se, antes de serem

apreciadas, em **sessão separada**, pelo **plenário** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Sendo assim, conforme anotou a Corte, o procedimento estabelecido na Res. n. 1/2002-CN, que permite a emissão de parecer por meio de relator nomeado, e não pela comissão mista, é **inconstitucional**.

Apesar de o mencionado parecer ser **opinativo**, isso não autoriza o Parlamento a violar a regra contida no art. 62, § 9.º, da CF/88. Se eventualmente não houver apreciação pela comissão mista, significa que a MP foi rejeitada por não apreciação, perdendo a sua eficácia desde a sua edição (art. 62, § 3.º, da CF/88).

Dessa forma, o STF declarou a **inconstitucionalidade dos arts. 5.º, caput, e 6.º, caput, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN**.

O ponto interessante é que, durante todo esse tempo, ou seja, por mais de 10 anos, o Congresso Nacional adotou esse “costume” (**inconstitucional**) de não fazer cumprir a regra de atuação da comissão mista, contentando-se com a permissão de parecer por relator designado, antes da apreciação em sessão separada pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Em julgamento anterior, o Min. Gilmar Mendes, na linha do dito *costume inconstitucional*, havia flexibilizado a exigência do art. 62, § 9.º, da CF/88, nos seguintes termos: “(...) considerando que ainda estamos em uma **fase de consolidação do novo modelo** trazido pela Emenda 32 para as medidas provisórias, não vejo como adotar interpretação com os rigores pretendidos pelo requerente na ADI 3.289. No caso, resta evidenciado que por duas vezes foi convocada a reunião para instalação da Comissão, não se chegando, todavia, ao *quorum* necessário. Essa falha procedimental, considerado o **atual estágio de implementação** da Emenda 32, assim como as **circunstâncias do caso**, em que resta demonstrada a tentativa, por duas vezes, de instalação da comissão mista, no meu entendimento, **ainda** não permite a formulação de um juízo de inconstitucionalidade por ofensa ao referido § 9.º” (**ADI 3.289** e **ADI 3.290**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.05.2005, Plenário, *DJ* de 24.02.2006).

Surgia, então, o impasse. Se o procedimento contido na Res. n. 1/2002-CN

foi declarado inconstitucional, que fazer em relação a todas as medidas provisórias que foram convertidas em lei sem a emissão de parecer pela comissão mista, na forma do art. 62, § 9.º, da CF/88?

Em tese, seriam todas inconstitucionais. Para evitar essa situação de **insegurança jurídica** e diante do **excepcional interesse social**, a Corte determinou a aplicação do art. 27 da Lei n. 9.868/99 (modulação dos efeitos da decisão), declarando a inconstitucionalidade do procedimento fixado na Res. n. 1/2002-CN a partir da decisão proferida na **ADI 4.029** — efeito *ex nunc* (j. 08.03.2012).

Assim, o modelo de apreciação da medida provisória fixado na resolução do Congresso Nacional foi declarado **“ainda constitucional”** até o julgamento da referida ADI 4.029 e, a partir de então, o STF declarou inconstitucional qualquer inobservância ao art. 62, § 9.º, da CF/88, ficando, por consequência, **preservadas a validade e a eficácia** de todas as medidas provisórias convertidas em lei até aquela data, bem como daquelas que estavam tramitando no Legislativo nos termos do procedimento fixado nos arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput* e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN, que permitiam a continuidade do iter procedimental de apreciação da medida provisória mesmo na hipótese de não haver parecer emitido pela comissão mista no prazo rígido de 14 dias contados da sua publicação.

■ 6.7.1.7. “Inconstitucionalidade circunstancial”

O tema agora é diferente do analisado no item anterior.

Busca-se, diante de uma lei formalmente constitucional, identificar que, **circunstancialmente**, a sua aplicação caracterizaria uma inconstitucionalidade, que poderíamos até chamar de **axiológica**.

Trata-se daquilo que foi denominado pela doutrina **“inconstitucionalidade circunstancial”** e, por que não, fazendo um paralelo não muito rígido com o tema anterior, de uma **“lei ainda inconstitucional”** em determinadas situações (enquanto persistirem certas circunstâncias).

Como bem afirma Barcellos, “trata-se da *declaração de inconstitucionalidade da norma produzida pela incidência da regra sobre uma determinada situação específica*... É possível cogitar de situações nas quais um enunciado normativo, válido em tese e na maior parte de suas incidências, ao ser confrontado com determinadas **circunstâncias concretas**, produz uma norma inconstitucional. Lembre-se que, em função da complexidade dos efeitos que se pretendam produzir e/ou da multiplicidade de circunstâncias de fato sobre as quais incidem, também as **regras** podem justificar diferentes condutas que, por sua vez, vão dar conteúdo a normas diversas. Cada uma dessas normas opera em um ambiente fático próprio e poderá ser confrontada com um conjunto específico de outras incidências normativas, justificadas por enunciados diversos. Por isso, não é de estranhar que **determinadas normas possam ser inconstitucionais em função desse seu contexto particular, a despeito da validade geral do enunciado do qual derivam**”. [146](#)

Como interessante exemplo, destacamos a **ADI 223**, na qual se discutia a constitucionalidade de normas que proibiam a concessão de tutela antecipada e liminares em face da Fazenda Pública.

Sem dúvida, diz Barcellos, a análise pelo Judiciário seria diferente para duas situações distintas: **a)** reenquadramento de servidor público; **b)** concessão de tutela antecipada para que o Estado custeasse cirurgia de vida ou morte.

Nesse segundo caso, sem dúvida, dada a circunstância, a lei seria inconstitucional, especialmente diante do art. 5.º, XXXV.

Outro exemplo interessante é a **ADI 4.068**, ajuizada pela OAB e que tem por objeto, em razão da criação da Super-Receita (Lei n. 11.457/2007), a regra contida no art. 16, § 1.º, que determina que a partir de 1.º de abril de 2008 toda a dívida ativa da União seja transferida para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Alega a OAB que, nas atuais **circunstâncias**, a PGFN não teria condições materiais e de recursos humanos para os mais de R\$ 401 bilhões (dívida ativa inscrita em 2006), sendo que “a carga de trabalho criada é desumana”.

Conforme noticiado, “sem que os 1.200 cargos criados na PGFN pela própria

lei, em seu artigo 18, sejam providos, a instituição não poderá atuar na representação judicial, afirma a ordem. A presente ADI, justifica a autora, ‘em essência, baseia-se nas sérias e jurídicas preocupações quanto à possibilidade administrativa de a PGFN assumir, de imediato, o grande acréscimo de trabalho a ser suportado a partir de abril do corrente ano, quando se dará a assunção de todo o passivo tributário resultante da criação da Super-Receita’, conclui a OAB, pedindo ao Supremo que declare a **inconstitucionalidade ‘circunstancial’** do artigo 16, parágrafo 1.º, da Lei 11.457/2007” (*Notícias STF*, 15.04.2008. O parecer da PGR é pela improcedência do pedido) **(matéria pendente de julgamento pelo STF)**.

■ 6.7.1.8. O efeito vinculante para o Legislativo e o inconcebível fenômeno da “fossilização da Constituição”

Como veremos e já comentamos em outro estudo, [147](#) o efeito vinculante em ADI e ADC, na linha de interpretação dada pelo STF, não atinge o Poder Legislativo no exercício de sua **função típica de legislar**, produzindo eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do **Poder Judiciário** e à **Administração Pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (exceto, entendemos, no exercício por esses órgãos de suas funções atípicas de caráter normativo como, para se ter um exemplo, quando o Presidente da República edita medida provisória — ato normativo).

Ao analisar a possibilidade de vinculação também para o Legislativo (no caso de sua função típica), o Ministro Cezar Peluso indica, com precisão, que essa possível interpretação (diversa da literalidade constitucional) significaria o **“inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição”**.

O Legislativo, assim, poderá, inclusive, legislar em sentido diverso da decisão dada pelo STF, ou mesmo contrário a ela, sob pena, em sendo vedada essa atividade, de significar inegável **petrificação** da evolução social.

Isso porque o valor **segurança jurídica**, materializado com a ampliação dos efeitos *erga omnes* e *vinculante*, sacrificaria o valor **justiça da decisão**, já que

impediria a constante atualização das Constituições e dos textos normativos por obra do Poder Legislativo.

A mesma orientação poderá ser adotada, também, para o efeito vinculante da súmula, que, em realidade, possui idêntica significação prática em relação ao efeito vinculante do controle concentrado de constitucionalidade.

Entendimento diverso manifestou o Ministro Peluso: “... comprometeria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o legislador, reduzindo este a papel subalterno perante o poder incontrolável daquele, com evidente prejuízo do espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo” ([Rcl 2.617](#), [Inf. 386/STF](#)).

■ **6.7.1.9. Município putativo. Princípio da reserva do impossível. Princípio da continuidade do Estado. Princípio federativo. Princípio da segurança jurídica. Princípio da confiança (Karl Larenz). Princípio da força normativa dos fatos (Georg Jellinek). Princípio da situação excepcional consolidada — ADI 2.240/BA — voto do Min. Eros Grau. Voto do Min. Gilmar Mendes — Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Efeito prospectivo. Possibilidade inédita do fenômeno da constitucionalidade superveniente. Dogma da nulidade da lei e garantia da segurança jurídica**

No julgamento da [ADI 2.240](#), ajuizada pelo PT contra a Lei n. 7.619/2000, do Estado da Bahia, o STF analisou o processo de criação do *Município de Luís Eduardo Magalhães* tendo em vista o desmembramento de área do Município de Barreiras.

Dentre os principais argumentos da inconstitucionalidade da lei destacava-se a violação ao art. 18, § 4.º, [148](#) da CF, na medida em que:

- o novo Município foi criado em ano de eleições municipais;
- não existia lei complementar federal fixando período para criação de Municípios;
- a nova lei estadual violou o regime democrático, na medida em que a consulta prévia plebiscitária não foi realizada com a totalidade da população envolvida no processo de emancipação, mas somente em

relação à população do Município que se formou;
os estudos de viabilidade municipal foram publicados em momento posterior ao plebiscito.

Resumindo, a criação do novo Município violou, frontalmente, a regra do art. 18, § 4.º, fato esse, inclusive, reconhecido pelo relator, Ministro Eros Grau.

Contudo, tendo em vista a **excepcionalidade do caso**, o Ministro Eros Grau “... julgou improcedente o pedido. Asseverou que o aludido Município fora efetivamente criado a partir de uma decisão política, assumindo existência de fato como ente federativo dotado de autonomia há mais de 6 anos e que esta realidade não poderia ser ignorada. Afirmou, no ponto, que esse ente assumira existência e, desta, resultaram efeitos jurídicos. Ressaltou, ainda, que a situação existente no momento da criação do citado Município era anormal, haja vista a não edição de lei complementar dentro de prazo razoável. Ponderando aparente conflito de inconstitucionalidades, quais sejam ofensas ao § 4.º do art. 18 da CF ou ao princípio federativo, entendeu que a existência válida do Município deveria ser reconhecida, para afastar a ofensa à federação. Nesse sentido, considerou os princípios da segurança jurídica e da continuidade do Estado. Salientando que, não obstante a criação desse ente tenha implicado situação excepcional não prevista pelo direito positivo, aduziu que a declaração de improcedência do pedido não servirá de estímulo à criação de novos municípios indiscriminadamente, mas, ao contrário, servirá de apelo ao Poder Legislativo, no sentido de suprir a omissão constitucional reiteradamente consumada. Após, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista” (ADI 2.240/BA, Rel. Min. Eros Grau, 18.05.2006 — *Inf.* 427/STF). [149](#)

O Ministro Eros Grau, assim, consagrou diversos, por ele ditos, “princípios”, que podem ser enumerados: [150](#)

■ **Município putativo** — à semelhança do que acontece com o casamento putativo e a sociedade de fato;

■ **princípio da “reserva do impossível”** — “a diferença entre o casamento putativo e o ‘Município putativo’ está em que, embora possível a anulação do primeiro, a anulação da decisão política de que resultou a

criação do Município avança sobre o que poderíamos chamar de ‘reserva do impossível’, no sentido de não ser possível anularmos o fato dessa decisão política de caráter institucional sem agressão ao princípio federativo”;

■ **princípio da continuidade do Estado** — que encontra fundamento no art. 1.º da CF e não se confunde com o princípio da continuidade do serviço público;

■ **princípio federativo** — justifica a não anulação da decisão política de caráter institucional;

■ **princípio da segurança jurídica** — que assegura a preservação da realidade de fato, qual seja, a existência de Município criado há mais de 6 anos;

■ **princípio da confiança (Karl Larenz)** — tendo como componente a ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé;

■ **princípio da força normativa dos fatos (Georg Jellinek)** — o Município foi efetivamente criado, assumindo existência de fato como ente federativo dotado de autonomia municipal a partir de uma decisão política;

princípio da situação excepcional consolidada — “não prevista pelo direito, porém instalada pela força normativa dos fatos” e “justificada” pela inércia do Poder Legislativo que até então não editara a lei complementar federal fixando prazo para criação de novos Municípios, como determinou a EC n. 15/96, que deu nova redação ao art. 18, § 4.º, da CF/88. Assim, “a não edição da lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia autêntica violação da ordem constitucional”.

Embora bastante sedutora a tese, com todo o respeito, já havíamos manifestado (*na 11. ed. deste estudo*) a nossa discordância, uma vez que não parecia razoável o resultado da construção (declaração de *constitucionalidade* da lei), o que poderia abrir precedentes para novas violações ao art. 18, § 4.º.

Em certa medida, tendo em vista o princípio da razoabilidade, a inexistência, até hoje (desde a EC n. 15, de 12.09.1996), de lei complementar federal fixando prazo e procedimento para a criação de novos Municípios até poderia ser superada. Contudo, não achávamos nada razoável a violação dos outros

pressupostos constitucionais, como a necessidade de estudo de viabilidade prévio e da consulta plebiscitária a toda a população diretamente interessada (a da área a ser desmembrada e a da área que se desmembra). Assim, a criação de novos Municípios, sem o cumprimento desses requisitos, ensejaria a configuração de inevitável **vício formal** de inconstitucionalidade por violação a pressupostos objetivos do ato.

Havíamos alertado que a jurisprudência pacífica do STF se consolidou no sentido da total observância dos pressupostos e condições de procedibilidade do art. 18, § 4.º. [151](#)

Nessa linha, nos termos do voto-vista do Min. Gilmar Mendes, o Plenário do STF declarou inconstitucional a Lei baiana n. 7.619/2000, mas não pronunciou a nulidade do ato, mantendo sua vigência por mais 24 meses. O Min. Eros Grau, por sua vez, revendo o seu voto inicial, acompanhou o voto do Min. Gilmar Mendes também no sentido de declarar a inconstitucionalidade, mas não a nulidade pelo prazo de 24 meses.

Utilizando a *técnica alternativa* de ponderação entre o **princípio da nulidade da lei**, de um lado, e o **princípio da segurança jurídica**, de outro, entendeu o STF que a lei é inconstitucional, mas, aplicando o art. 27 da Lei n. 9.868/99, e tendo em conta razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, apesar de inconstitucional por violar o art. 18, § 4.º, deverá continuar vigorando por 24 meses.

Consagra-se, dessa forma, a técnica da **declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade**, já que, dependendo do caso concreto, como disse o Min. Gilmar Mendes, a “... nulidade da lei inconstitucional pode causar uma **verdadeira catástrofe** — para utilizar a expressão de Otto Bachof — do ponto de vista político, econômico e social”.

Observa Gilmar Mendes que o princípio da nulidade continua a ser a regra. “O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucional manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, aqui, como no

direito português, a não aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento constitucional próprio”.

E, no Brasil, há uma particularidade de aspecto procedimental, qual seja, o *quorum* qualificado de 2/3 dos votos dos Ministros para reconhecer a **modulação de efeitos** com a possibilidade de estabelecer efeitos prospectivos, ou *pro futuro*, ou a partir do momento que o STF entender razoável.

Nesse caso concreto, o prazo de *24 meses* foi o que o STF entendeu ser possível para corrigir a situação, até porque, no julgamento da **ADO 3.682**, os Ministros reconheceram razoável o prazo de *18 meses* para o Congresso Nacional elaborar a lei complementar federal e, assim, dar cumprimento ao dispositivo fixado no art. 18, § 4.º, pela EC n. 15/96 (nova regra que o STF, inclusive, já declarou constitucional e como “freio” para o crescimento exagerado do número de Municípios). [152](#)

Trata-se de reconhecimento da omissão com **apelo ao legislador**, para que elabore a lei dentro de 18 meses. Elaborada a lei complementar federal, os Municípios terão o prazo de mais 6 meses (já que se fixou em 24 meses o prazo de vigência das leis estaduais) para corrigir os vícios.

Parece-nos, aqui, que o STF, **diferentemente do entendimento que ainda adota como regra**, [153](#) admitiu, para esse caso concreto, uma **inédita** e inegável possibilidade do fenômeno da **constitucionalidade superveniente**, permitindo que uma lei que nasceu viciada (*vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato*) seja corrigida mediante um procedimento futuro de adequação ao art. 18, § 4.º.

E se não for elaborada referida LC federal pelo CN?

Conforme será discutido no *item 6.7.4.9* (julgamento da *ADO 3.682*), o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional elabore a LC federal nos termos do art. 18, § 4.º, foi fixado no dispositivo da decisão, tendo, assim, na linha de proposta da doutrina alemã, **caráter mandamental** (cf. a íntegra do acórdão — de *indispensável leitura* —, 50 laudas, no site do STF, bem como *Inf. 466/STF*).

Nossa impressão é de que teria sido imposta ao Congresso Nacional a obrigatoriedade de elaborar a lei e, assim, se descumprida, tendo a decisão caráter mandamental, parece que o STF poderia determinar a elaboração ou, quem sabe, inclusive, por analogia, dentro da ideia de travamento de pauta, ou algum instrumento que derive do art. 64 e seus parágrafos, determinar medida coercitiva para o cumprimento ou, ainda, na tendência de controle de omissões, manifestada pelo STF no julgamento do **MI 712** (cf. *item 14.11.5.4*), quem sabe, até mesmo, suprir a omissão.

Cabe alertar, todavia, que, restringindo nossa opinião, o **Ministro Presidente do STF** determinou, em **12.09.2008**, por meio do *Ofício n. 346/GP*, fosse esclarecido ao Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhando o inteiro teor do acórdão de fls. 132-187: **“não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável**, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI ns. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios”.

E se, elaborada a LC federal, os Municípios não se adequarem ao novo procedimento?

Como disse a Ministra Ellen Gracie, o STF deu **sobrevida** à legislação atacada e fixou o prazo (para esta sobrevida) de 24 meses. Nesse sentido, nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “até 24 meses porque, aí, ou ele estará criado por novos atos ou estará **desconstituído**”, ficando, assim, na interpretação do Min. Marco Aurélio, o Município submetido a uma **condição resolutive**. Dessa forma, pelo exposto nas discussões da ADI 2.240, o Município deixaria de existir, voltando ao *statu quo ante*.

Por fim, lembramos que a **EC n. 57/2008** buscou convalidar os vícios indicados, tema que será discutido nos *itens 6.7.4.9 e 7.6.1*.

■ **6.7.1.10. “Princípio” da proibição do “atalhamento constitucional” e do “desvio de poder constituinte” (utilização de meio aparentemente legal buscando atingir finalidade ilícita)**

Conforme veremos no *capítulo 18* deste trabalho (*item 18.4*), a **EC n. 52/2006** buscou acabar, de vez, com a regra consagrada pelo TSE (*Res. n. 21.002/2002*) da obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias em razão do caráter nacional dos partidos políticos.

Ao modificar o art. 17, § 1.º, da CF/88, a EC n. 52/2006 estabeleceu ser assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, **sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal**, devendo seus estatutos prever normas de disciplina e fidelidade partidária.

O art. 2.º da EC n. 52/2006, por sua vez, determinou a aplicação do novo preceito (que acabava com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias) às eleições que ocorreram no ano de 2002. Sem dúvida o objetivo dessa remissão era fazer com que a regra, supostamente direcionada para as eleições de 2002, pudesse já ser aplicada às eleições de 2006, na medida em que, aparentemente, intacto estaria o princípio contido no art. 16 da CF/88.

Como se sabe (e estudaremos no *capítulo 18*), o art. 16 da CF/88 consagra o **princípio da anualidade** ao dispor que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, **não se aplicando à eleição que ocorra em até um ano da data de sua vigência**.

O objetivo do art. 16 é assegurar a estabilidade e a segurança jurídica do processo eleitoral, evitando que as regras mudem no “meio do jogo”. Ou seja, a regra pode mudar, contudo só valerá a partir de um ano de sua vigência.

Pode-se afirmar, com o Ministro *Ricardo Lewandowski*, em seu voto, [154](#) que a manobra empreendida pelo Constituinte Reformador (EC n. 52/2006) “... incorre no vício que os publicistas franceses de longa data qualificam de

détournement de pouvoir, isto é, de ‘desvio de poder ou de finalidade’, **expediente mediante o qual se busca atingir um fim ilícito utilizando-se de um meio aparentemente legal**”.

E continua: “em outras palavras, repita-se, buscou-se, no caso, como se viu, **atalhar** o princípio da anualidade, dando efeito retroativo à Emenda 52, promulgada em plena vigência do moralizador artigo 16 da Carta Magna. Trata-se, nas palavras do ilustre Professor Fábio Konder Comparato, que elaborou parecer sobre a matéria, de um ‘desvio de poder constituinte’, que os autores alemães denominam *Verfassunsbeseitigung*, expressão que, traduzida literalmente, significa **‘atalhamento da Constituição’**”.

Consagra-se, portanto, o princípio que veda qualquer mecanismo a ensejar o **“atalhamento da Constituição”**, vale dizer, qualquer artifício que busque abrandar, suavizar, abreviar, dificultar ou impedir a ampla produção de efeitos dos princípios constitucionais, como, no caso, do princípio da *anualidade do processo eleitoral*.

■ 6.7.1.11. Inconstitucionalidade “chapada”, “enlouquecida”, “desvairada”

A expressão “chapada” começou a ser utilizada pelo Min. Sepúlveda Pertence quando queria caracterizar uma inconstitucionalidade mais do que **evidente, clara, flagrante, escancarada**, não restando qualquer dúvida sobre o vício, seja formal, seja material.

Atualmente, vem sendo utilizada pelos Ministros, sempre no sentido inaugurado pelo Min. Pertence, destacando-se alguns julgados, como ADI 2.527, ADI 3.715, ADI 1.923-MC (cf. *Inf. 474/STF*), ADI 1.802-MC etc.

Inovando, o Min. Carlos Britto, no sentido de descrever uma inconstitucionalidade **manifesta**, chegou a caracterizá-la como **“enlouquecida, desvairada”** (ADI 3.232).

■ 6.7.1.12. Início da eficácia da decisão que reconhece a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de lei em processo

objetivo de controle abstrato

De modo geral, o STF entende que a decisão passa a valer a partir da **publicação da ata de julgamento no DJE**, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, “exceto nos casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão” (cf. **ADI 711-QO**, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.08.1992, *DJ* de 11.06.1993 — critério adotado em julgamento de medida cautelar, mas que parece se adequar ao julgamento de mérito); Rcl 2.576 e *Notícias STF*, 23.06.2004; Rcl 3.309 e *Inf. 395/STF*; ADI 3.756-ED, Rel. Min. Carlos Britto, j. 24.10.2007, *DJ* de 23.11.2007). Nesse sentido:

“EMENTA: 1. **Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida.** Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade — ADI 2.335 — a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no *Diário da Justiça* da ata da sessão de julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração, cuja consequência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC/73), **não impede a implementação da decisão.**¹⁵⁵ Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente” (**Rcl 2.576**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2004, *DJ* de 20.08.2004).

Dessa forma, para a jurisprudência do STF, não se pode confundir, em se tratando de **ações objetivas de controle de constitucionalidade**,¹⁵⁶ a publicação da **ata de julgamento** com a publicação do **acórdão**.

O efeito da decisão passa a valer, **inclusive para eventual interposição de reclamação**, a partir da publicação da **ata** de julgamento no *DJE*. Publicado o acórdão, em momento seguinte, inicia-se o prazo para a interposição de eventual recurso, no caso dos processos objetivos em análise, dos embargos

declaratórios. Só então, julgados os embargos, é que haverá a **certificação** do trânsito em julgado da decisão, sem que isso impeça, como visto, desde a publicação da ata, a produção dos **efeitos** da decisão. Pedimos, novamente, vênha para destacar a jurisprudência do STF:

“1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia *erga omnes* desde a publicação da **ata** de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (**Rcl 3.632-AgR**, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, *DJ* 18.08.2006. Nesse sentido, cf. decisão monocrática da Min. Cármen Lúcia na RCL 17.446, j. 31.03.2014). [157](#)

Para **abreviar** esse período (publicação da ata de julgamento e publicação do acórdão, com a certificação do trânsito em julgado), que em muitos casos já chegou a levar anos, **destacamos a Portaria n. 536/STF, de 16.10.2014**, que dispõe sobre o prazo para a publicação de acórdãos e já vem surtindo efeitos relevantes (para se ter uma ideia da gravidade da situação, mesmo diante da regra contida no art. 5.º, LXXVIII, CF/88, que trata da celeridade enquanto garantia fundamental, quando da publicação da referida Resolução, havia a pendência de publicação de cerca de 2.000 acórdãos proferidos pelas Turmas e pelo Plenário do STF!).

■ 6.7.1.13. Competência (ADI genérica)

A competência para processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade será definida em conformidade com a natureza do objeto da ação, qual seja, lei ou ato normativo: federal, estadual, municipal ou distrital. Vejamos as hipóteses.

■ 6.7.1.13.1. Lei ou ato normativo federal ou estadual em face da CF

O art. 102, I, “a”, da CF/88 estabelece que compete ao **STF**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, **originariamente**, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) de **lei ou ato normativo federal ou estadual**. Trata-se de controle concentrado, sendo a ação proposta diretamente no STF, de forma originária. Assim:

Lei ou ato normativo **federal/estadual** que contrariar a **CF** **STF**.

■ 6.7.1.13.2. *Lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da CE*

O art. 125, § 2.º, da CF/88 dispõe que caberá aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de **leis ou atos normativos estaduais ou municipais** em face da **CE**, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Ou seja, cada estado criará o seu sistema de controle concentrado de constitucionalidade, mas agora de lei ou ato normativo estadual ou municipal que contrariarem a Constituição do aludido Estado-Membro. Quem terá competência para o julgamento será o **Tribunal de Justiça do Estado** (TJ). [158](#) Vejamos o esquema:

Lei ou ato normativo **estadual/municipal** que contrariar a **CE** **TJ local**.

■ 6.7.1.13.3. *Lei ou ato normativo municipal em face da CF*

Nesse caso, por falta de expressa previsão constitucional, seja no art. 102, I, “a”, seja no art. 125, § 2.º, **inexistirá controle concentrado por ADI**. O máximo que pode ser feito é o controle via sistema difuso, podendo a questão levada ao judiciário, através do recurso extraordinário, de forma incidental, ser apreciada pelo STF e ter a sua eficácia suspensa, pelo Senado Federal, nos exatos termos do art. 52, X.

Esse silêncio acerca da hipótese do aludido controle concentrado, de forma proposital, é chamado, como lembram Araujo e Nunes Júnior, de **silêncio eloquente**. [159](#)

Nesse sentido, o STF, pela ADI 347-SP, corroborando o entendimento acima

exposto, suspendeu a eficácia do art. 74, XI, da CE/SP, que dizia ser o controle das leis municipais que contrariassem a CF feito pelo TJ local.

Havendo repetição da norma da CF pela CE (**normas repetidas**), o entendimento é o de que, apesar de incabível o controle de constitucionalidade concentrado perante o STF (da lei ou ato normativo municipal tendo por paradigma de confronto a CF), será perfeitamente possível a realização do controle concentrado perante o TJ local, confrontando-se a lei municipal em face da CE que repetiu norma da CF, mesmo em caso de norma da CE de **repetição obrigatória e redação idêntica** à norma da CF (cf. STF, Rcl 383-SP, REMC 16.390-AL e Rcl 386-8/SC, Rel. Min. Octavio Gallotti).

Nesse caso é de destacar a possibilidade de cabimento de **recurso extraordinário** a ser julgado pelo STF quando a norma que serviu de parâmetro de controle da CE for norma de reprodução obrigatória, repetida e copiada da CF, tema que será estudado no *item 6.8.6*.

Confrontar, por fim, a discussão exposta acima com a **arguição de descumprimento de preceito fundamental**, estabelecida no art. 102, § 1.º, da CF/88, regulamentada pela Lei n. 9.882/99 e por nós comentada no *item 6.7.3*, que admite referida ação tendo por objeto lei municipal perante a CF/88!

Como regra geral, o esquema é o seguinte:

Lei ou ato normativo **municipal** que contrariar a **CF** **não há controle concentrado através de ADI, só difuso. Há, contudo, a possibilidade de ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto lei municipal confrontada perante a CF.**

■ 6.7.1.13.4. *Lei ou ato normativo distrital em face da CF/88*

No tocante ao Distrito Federal, o poder constituinte originário de 1988 deixou de fazer previsão expressa ao controle de constitucionalidade das leis emanadas do legislativo do Distrito Federal.

Apesar disso, o art. 32, § 1.º, dispõe que ao Distrito Federal são atribuídas as

competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. Assim, o controle concentrado a ser exercido pelo STF será possível ou não, de acordo com a natureza da norma constitucional elaborada pelo Distrito Federal. Vejamos:

Lei ou ato normativo **distrital** de **natureza estadual** que contrariar a **CF STF**;

Lei ou ato normativo **distrital** de **natureza municipal** que contrariar a **CF não há controle concentrado através de ADI, 160 só difuso**. Há, contudo, a possibilidade do ajuizamento da **arguição de descumprimento de preceito fundamental** tendo por objeto lei ou ato normativo **distrital**, de natureza **municipal**, confrontada perante a **CF**.

■ 6.7.1.13.5. *Lei ou ato normativo distrital em face da Lei Orgânica Distrital*

De acordo com o art. 32, *caput*, da CF/88, o Distrito Federal, vedada a sua divisão em Municípios, reger-se-á por **lei orgânica**. Indagamos, então: seria possível o controle concentrado de lei ou ato normativo distrital, em face da Lei Orgânica Distrital?

Fazendo pesquisa na jurisprudência do TJDF, encontramos julgados permitindo o referido controle, corroborados pelo Regimento Interno do TJDF (arts. 206 a 209). Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei local em face da LODE. Competência. Liminar. Requisitos. I — o leito processual adequado para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de **lei local em face da lei orgânica do Distrito Federal** é a ação direta de inconstitucionalidade. II — não há lacunas na Constituição Federal relativamente à competência para o processo e julgamento da ADI. Ocorre, tão só, falta de explicitude da Lei Maior. Tal competência é afeta ao **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**, por interpretação sistemática, quanto ao método, e extensiva, quanto ao alcance, dos arts. 125, § 2.º, e 32, § 1.º, da CF. III — o procedimento a ser adotado na ADI encontra-se descrito no *RISTF*, de aplicação subsidiária” (destacamos). [161](#)

Esse entendimento jurisprudencial passou a encontrar expresso amparo legal.

A **Lei n. 9.868/99**, que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e da ADC perante o STF, alterou a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 8.185/91), acrescentando a alínea “n” ao inciso I do art. 8.º, que atribui competência ao TJ local para processar e julgar, originariamente, a *ADI de lei ou ato normativo do DF em face da sua Lei Orgânica*.

Referida lei foi revogada pela **Lei n. 11.697/2008** (lei federal que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), que manteve a mencionada competência no art. 8.º, I, “n” e, ainda, estabeleceu, na alínea “o”, a atribuição para processar e julgar, originariamente, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua Lei Orgânica.

A previsão da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão), que já constava no art. 30 da Lei n. 9.868/99, foi mantida no art. 8.º, § 4.º, II, da Lei n. 11.697/2008.

Ainda, seguindo a orientação da Lei n. 9.868/99, nos termos do art. 8.º, § 5.º, da comentada Lei n. 11.697/2008, ficou mantida a regra no sentido de se aplicarem, no que couber, ao processo e julgamento da **ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica**, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

Esse entendimento, qual seja, apresentar-se a **Lei Orgânica do DF** como parâmetro ou paradigma de confronto, encontra-se pacificado na jurisprudência do STF:

“EMENTA: Antes de adentrar no mérito da questão aqui debatida, anoto que, muito embora não tenha o constituinte incluído o Distrito Federal no art. 125, § 2.º, que atribui competência aos Tribunais de Justiça dos Estados para instituir a representação de inconstitucionalidade em face das constituições estaduais, a Lei Orgânica do Distrito Federal apresenta, no dizer da doutrina, a natureza de verdadeira Constituição local, ante a autonomia política, administrativa e financeira que a Carta confere a tal ente federado. Por essa razão, entendo que se mostrava cabível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pelo MPDFT no caso em exame” (RE 577.025, voto do

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.12.2008, Plenário, *DJE* de 06.03.2009).

■ 6.7.1.13.6. *Lei municipal em face da lei orgânica do Município*

Nesse caso não estaremos diante de controle de constitucionalidade, mas de simples controle de **legalidade**, cujas regras deverão ser explicitamente previstas na Lei Orgânica de cada Município.

Manoel Carlos, de forma interessante, reconhecendo a natureza constitucional da lei orgânica de Município, sugere que a possibilidade de controle seja pela via incidental, como **abstratamente**, lembrando a previsão de controle concentrado de lei municipal em face da lei orgânica, nos termos do art. 61, I, “I”, da Constituição do Estado de Pernambuco. [162](#)

Resta aguardar como o STF vai evoluir sobre esse assunto (**matéria pendente**), mostrando-se bastante sedutora a proposta doutrinária.

Por enquanto, contudo, parece que a melhor orientação (no caso dos *concursos públicos*) seria seguir a conclusão de André Ramos Tavares, no sentido de que o controle seria feito pelo **sistema difuso** apenas. [163](#)

■ 6.7.1.14. *Legitimidade (ADI genérica)*

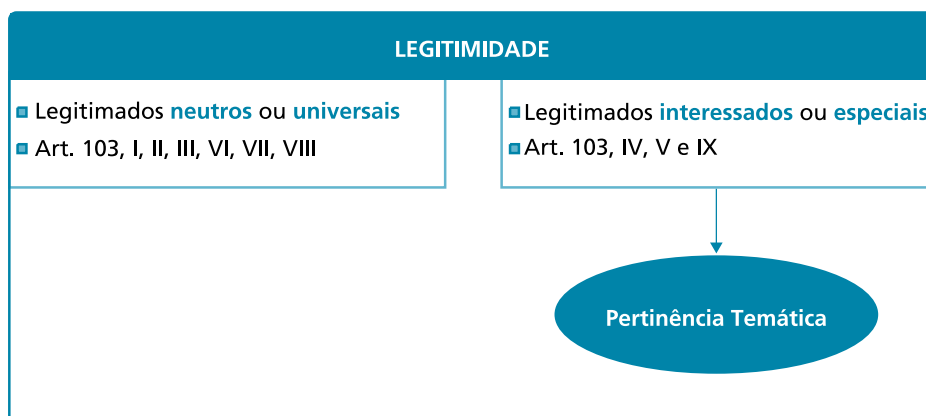
No tocante à legitimidade, estudaremos os legitimados para a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal, contestados em face da CF, sendo julgada pelo STF.

As partes legítimas para propositura da ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, contestados em face da CE perante o TJ local, serão especificadas em cada Constituição Estadual. O art. 125, § 2.º, CF/88, veda, no âmbito estadual, a atribuição da legitimação a um único órgão (cf. *item 6.8.4*).

A CF/88, ampliando o rol de legitimados, que até 1988 apenas se limitava ao Procurador-Geral da República (PGR), previu, em seu art. 103, que a ADI

genérica, para questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual contestados em face da própria CF, poderá ser proposta (no plano da ADI no STF, o **rol** é **taxativo** — *numerus clausus*):

- I** — pelo Presidente da República;
- II** — pela Mesa do Senado Federal;
- III** — pela Mesa da Câmara dos Deputados; [164](#)
- IV** — pela Mesa de Assembleia Legislativa de Estado ou pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (alterado pela EC n. 45/2004); [165](#)
- V** — pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal (alterado pela EC n. 45/2004); [166](#)
- VI** — pelo Procurador-Geral da República;
- VII** — pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII** — por partido político com representação no Congresso Nacional; [167](#)
- IX** — por confederação sindical [168](#) e [169](#) ou entidade de classe [170](#) de âmbito nacional. [171](#)



Quanto aos legitimados, o STF prescreve que alguns devem demonstrar interesse na aludida representação, em relação à sua **finalidade institucional**. Todos os membros acima citados são **neutros** ou **universais**, possuidores de **legitimação ativa universal**, ou seja, não precisam demonstrar a **pertinência temática**, exceto os dos incisos **IV** — *Mesa de Assembleia Legislativa de Estado* (e, como vimos, também a Mesa da Câmara Legislativa); **V** — *Governador de Estado* (também o Governador do DF) e **IX** — *confederação*

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, que são autores **interessados** ou **especiais**, ou seja, devem demonstrar o interesse na propositura da ação relacionado à sua finalidade institucional.

E “associação de associação” pode ser classificada como entidade de classe para a propositura da ADI?

Inicialmente, o STF negou legitimidade ativa à Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) (ADI 591-MC/DF, *RTJ* 138/81) por se tratar de “associação de associação”.

Entretanto, a Suprema Corte **modificou o seu entendimento** ao analisar o caso concreto da *Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de Alambique (FENACA)*. Vejamos: “Associação de Associações: Legitimidade para ADI (Transcrições) (v. *Informativo* 356), ADI 3.153 AgR/DF, Relator p/ acórdão: Min. Sepúlveda Pertence. Voto: Presidente, volta ao Plenário um problema cuja solução, na jurisprudência da Corte, jamais, pessoalmente, me convenceu: é a que banuiu da legitimação para a ação direta de inconstitucionalidade o que se tem chamado ‘associação de associações’. A meu ver, nada o justifica. Chegou-se a falar que uma ‘associação de associações’ só poderia defender os interesses das suas associadas, vale dizer, das associações que congrega. Mas, *data venia*, o paralogismo é patente. A entidade é de classe, da classe reunida nas associações estaduais que lhe são filiadas. O seu objetivo é a defesa da mesma categoria social. E o fato de uma determinada categoria se reunir, por mimetismo com a organização federativa do País, em associações correspondentes a cada Estado, e essas associações se reunirem para, por meio de uma entidade nacional, perseguir o mesmo objetivo institucional de defesa de classe, a meu ver, não descaracteriza a entidade de grau superior como o que ela realmente é: uma entidade de classe. No âmbito sindical, isso é indiscutível. As entidades legitimadas à ação direta são as confederações, que, por definição, não têm como associados pessoas físicas, mas, sim, associações delas. **Não vejo, então, no âmbito das associações civis comuns não sindicais, como fazer a distinção.** Peço todas as vênias ao eminente Relator — aliás já discutimos a respeito, desde pelo menos o caso CUT e CGT, na ADI 271 (lembrando, como

visto em nota anterior, que o STF não admite a legitimação ativa das centrais sindicais citadas)¹⁷² — para dar provimento ao agravo regimental, a fim de que se processe a ação direta” (*Inf. 361/STF*).

E a perda de representação do partido político no Congresso?

Tendo em vista a importância do novo entendimento, já anunciado em nota anterior, cabe destacar que o STF decidiu que a perda de representação do partido político no Congresso Nacional, após o ajuizamento da ADI, não descaracteriza a legitimidade ativa para o prosseguimento na ação. Dessa forma, “... a aferição da legitimidade deve ser feita no momento da propositura da ação...” (ADI 2.159 AgR/DF, Rel. orig. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 12.08.2004. Vencidos o Min. Carlos Velloso, relator, e o Min. Celso de Mello, que consideravam que a perda da representação implicava a perda da capacidade postulatória).

E a necessidade de advogado?

O STF entendeu que somente os **partidos políticos** e as **confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional** é que precisarão contratar **advogado** para a propositura da ADI (art. 103, VIII e IX), devendo, no instrumento de mandato (procuração), haver a outorga de **poderes específicos** para atacar a norma impugnada, **indicando-a** (ADI 2.187-QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 24.05.2000, Plenário, *DJ* de 12.12.2003). Quanto aos demais legitimados (art. 103, I-VII), a capacidade postulatória decorre da Constituição.

Nesse sentido: “O Governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, **possuem capacidade processual plena** e dispõem, *ex vi*, da própria norma constitucional, de **capacidade postulatória**. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos ordinariamente

privativos de advogado” (ADI 127-MC/QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.11.1989, *DJ* de 04.12.1992).

■ 6.7.1.15. **Procedimento e características marcantes do processo objetivo (ADI genérica)**

O procedimento vem delimitado nos §§ 1.º e 3.º do art. 103 da CF/88, explicitado nos arts. 169 a 178 do *RISTF*, bem como nas regras trazidas pela Lei n. 9.868, de 10.11.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Como vimos, a ação será proposta por um dos legitimados do art. 103 da CF/88, que deverá indicar na petição inicial o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, bem como o pedido, com suas especificações.

De acordo com o parágrafo único do art. 3.º da Lei n. 9.868/99, corroborando a jurisprudência do STF, a petição inicial, quando subscrita por advogado, deverá vir acompanhada de **instrumento de procuração** (e, acrescente-se, outorgada com **poderes especiais** para a instauração do pertinente processo de controle normativo abstrato perante a Corte Constitucional, indicando, objetivamente, a lei ou o ato normativo e respectivos preceitos — quando for o caso — que estejam sendo levados à apreciação do Judiciário através da ADI — cf. STF, Pleno, ADI 2.187-7/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, *DJ* de 19.05.2000), e será apresentada em duas vias, [173](#) devendo conter cópia da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

O art. 4.º da Lei n. 9.868/99 estabelece que a **petição inicial inepta, não fundamentada** e a **manifestamente improcedente** serão liminarmente **indeferidas** pelo **relator**. Contra essa decisão que indeferir a petição inicial caberá o recurso de **agravo** a ser interposto no prazo de **5 dias** (cf. art. 317 do *RISTF*) e apreciado pelo **Pleno**.

De acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, se dar em **dias úteis**.

Naturalmente, em se tratando de decisão do **Pleno** da Corte que não conhece de ação direta de inconstitucionalidade, **não será cabível o agravo**, já que só admissível contra decisão do **relator** que liminarmente indefere petição inicial (ADI 2.073-AgRQO, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.10.2000, *DJ* de 24.11.2000).

A jurisprudência do STF considera **manifestamente improcedente** a ação direta de inconstitucionalidade que versar sobre norma cuja constitucionalidade já tenha sido expressamente declarada pelo Plenário da Corte, **mesmo que em recurso extraordinário** (ADI 4.071-AgR, j. 22.04.2009. No mesmo sentido: **ADI 4.466**, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 13.02.2012. Sobre a tendência de *objetivação do recurso extraordinário*, cf. *item 6.6.5.2*).

Em referido julgado ressaltou-se a possibilidade de alteração da jurisprudência do Pleno, o que, entretanto, “pressupõe a **ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica**, ou, quando muito, a **superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes**”, o que não se verificou.

Não sendo o caso de indeferimento liminar, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, devendo tais informações ser prestadas no prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido.

A jurisprudência do STF tem reconhecido a faculdade de o relator requisitar **informações complementares**, “... com o objetivo de permitir-lhe uma avaliação segura sobre os fundamentos da controvérsia” (ADI 2.982-ED e ADI

3.832, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 05.04.2010, *DJE* de 16.04.2010).

Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o **Advogado-Geral da União** e o **Procurador-Geral da República**, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 dias. O primeiro defenderá o ato impugnado, enquanto o segundo poderá dar parecer tanto favorável como desfavorável.

Temos percebido, **contudo**, algumas situações nas quais o AGU, segundo orientação do STF, “não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade” (*vide* ADI 1.616/PE, ADI 2.101/MS, ADI 3.121/SP e ADI 3.415/AM). Ainda, evoluindo a jurisprudência firmada na ADI 72, a partir da **interpretação sistemática**, na **ADI 3.916**, entendeu o STF que a AGU tem **direito de manifestação** (cf. os vários precedentes no *item 12.3.6.4*).

O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. Trata-se da importante figura do *amicus curiae* que discutimos no *item 6.7.1.16*.

Ainda, desde que haja necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o **relator** requisitar outras, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. [174](#)

Nesse particular, interessante destacar que somente em **20.04.2007** foi realizada, de modo inédito, a **primeira audiência pública** para o cumprimento do art. 9.º, § 1.º, da Lei n. 9.868/99. [175](#)

Tratava-se da ADI 3.510, proposta pelo PGR, contra a utilização de células-tronco de embriões humanos em pesquisas e terapias. “O PGR argumentava que ‘... a lei afronta a Constituição Federal no que diz respeito ao **direito à vida** e a **dignidade da pessoa humana**. Sustentava, com base na opinião de diversos especialistas em bioética e sexualidade, que a vida humana começa a partir da

fecundação e ressalta que ‘o embrião humano é vida humana’” (*Notícias STF*, 19.04.2007).

Conforme aprofundamos no *item 14.10.1.2*, o STF entendeu, por 6 x 5, que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida, nem mesmo a dignidade da pessoa humana, julgando, assim, improcedente a ADI 3.510.

O relator poderá, ainda, solicitar **informações** aos Tribunais Superiores, aos Tribunais Federais e aos Tribunais Estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição.

Finalmente, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para o julgamento.

A declaração de inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada (ou mesmo de constitucionalidade no caso de improcedência da ADI, em razão de seu caráter dúplice ou ambivalente) será proferida se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos **6** Ministros (**maioria absoluta** — art. 97 da CF/88), desde que observado o *quorum de instalação da sessão de julgamento*, qual seja, a presença de pelo menos 8 dos 11 Ministros (arts. 22 e 23 da Lei n. 9.868/99).

De acordo com o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória, confirmando, assim, a ambivalência das referidas ações.

Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato.

Como já apontamos, de modo geral, o STF entende que a decisão passa a

valer a partir da **publicação da ata da sessão de julgamento no DJE**, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, “exceto nos casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão” (cf. **ADI 711-QO**, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.08.1992, *DJ* de 11.06.1993 — critério adotado em julgamento de medida cautelar, mas que parece adequar-se ao julgamento de mérito; Rcl 2.576 e *Notícias STF*, 23.06.2004; Rcl 3.309 e *Inf. 395/STF*; ADI 3.756-ED, Rel. Min. Carlos Britto, j. 24.10.2007, *DJ* de 23.11.2007).

Nos termos do art. 28 da Lei n. 9.868/99, dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o STF fará publicar em seção especial do *Diário da Justiça* e do *Diário Oficial da União* a parte dispositiva do acórdão.

Por se tratar de **processo objetivo** de controle abstrato de constitucionalidade, algumas regras são muito importantes e particulares, destacando-se:

■ **inexistência de prazo recursal em dobro ou diferenciado para contestar**: a norma inscrita no art. 188 do CPC/73 (que determina que se compute em **quádruplo** o prazo para **contestar** e em **dobro** para **recorrer**, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público), restringe-se ao “... domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais”, **não** se aplicando, portanto, ao **processo objetivo** de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, *DJ* de 14.12.2001).

No CPC/2015, a regra geral passou a ser o **prazo em dobro** (não havendo previsão de prazo em quádruplo) para **todas as manifestações processuais** do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública (arts. 180, 183 e 186). Esse benefício da contagem em dobro, contudo, não se aplica quando a lei estabelecer, **de forma expressa, prazo próprio** para o Ministério Público, para o ente público ou para a Defensoria Pública (arts. 180, § 2.º, 183, § 2.º, e 186, § 4.º). Assim, como a Lei n. 9.868/99 prevê os prazos próprios, parece que a regra geral do prazo em dobro já estaria excepcionada pela própria

legislação.

Alertamos, contudo, **considerando o CPC/73**, que a orientação da existência do prazo diferenciado **poderá ser revista** pelo Pleno do STF. Destacamos **nova posição** firmada por 3 x 2 pela **1.ª Turma** do STF no julgamento de **recurso extraordinário** interposto em face de acórdão do TJSP em ADI estadual tendo por objeto lei municipal e hipótese de norma de reprodução obrigatória da CF na CE (sobre esse modelo processual, cf. *item 6.8.6*).

Conforme ponderou o Min. Dias Toffoli, Relator, **revendo o seu entendimento**, não haveria lógica aplicar o art. 188 do CPC/73 em RE no controle subjetivo e não o fazê-lo em **RE no controle objetivo**. “Com efeito, o recurso extraordinário está detalhadamente disciplinado no Código de Processo Civil e na Lei n. 8.038/90, sem que o legislador, em nenhum dos dois diplomas, tenha feito qualquer distinção com relação aos recursos interpostos em processos de natureza objetiva ou abstrata. Tampouco a Lei n. 9.868/99, que possui caráter de norma geral para os processos de controle abstrato, faz essa distinção. Se o próprio legislador não faz qualquer distinção, não cabe a nós, julgadores, fazê-la” (**ARE 661.288**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.05.2014, 1.ª T., *DJE* de 29.09.2014, fls. 7 do acórdão).

Deixamos a nossa **crítica** em relação à condução da questão processual debatida pelo **órgão fracionário** do STF no referido julgado. Em nosso entender, a decisão **contrariou**, frontalmente, o entendimento que **ainda prevalece** no **Pleno** do STF no sentido de **não se aplicar o art. 188 do CPC/73 nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade** (regra essa que também deveria ser aplicada em relação ao CPC/2015). [176](#) Deveriam ter afetado o RE ao Pleno, com o objetivo de se rever a jurisprudência que prevalece no sentido da sua inaplicabilidade ao recurso extraordinário interposto em **processos objetivos** (firme nesses termos o Min. Roberto Barroso em seu voto, apesar de vencido).

Devemos acompanhar a **eventual** evolução da jurisprudência da Corte (**pendente**, no caso, sobre o tema, no julgamento do **AI 827.810** afetado ao Pleno pela 1.ª Turma do STF em 28.06.2011 e ainda não apreciado). Em nossa

opinião, o prazo dobrado não se conforma às particularidades do processo objetivo, tanto é que a Lei n. 9.868/99 tem regras procedimentais próprias e distintas do CPC/73 (e do CPC/2015, quando entrar em vigor que, como visto, afasta, expressamente, a regra geral do prazo diferenciado). Na hipótese em discussão, estamos diante da utilização de recurso inerente ao processo subjetivo (controle difuso — RE) no processo objetivo (controle concentrado — ADI genérica), tanto é que a decisão proferida no acórdão do RE terá os mesmos efeitos da ADI genérica.

■ **inexistência de prazo prescricional ou decadencial;** [177](#)

■ **não admissão da assistência jurídica a qualquer das partes, nem intervenção de terceiros**, de acordo com o art. 169, § 2.º, do *RISTF* (conforme o art. 7.º da Lei n. 9.868/99), salvo a figura do *amicus curiae*; [178](#)

■ **vedada, expressamente, a desistência da ação proposta:** de acordo com o art. 5.º, *caput*, da Lei n. 9.868/99;

irrecorribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo: o art. 26 da Lei n. 9.868/99 estabelece a irrecorribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória, **ressalvada** a interposição de **embargos declaratórios**; [179](#)

Outra exceção a essa regra da irrecorribilidade, muito particular — e por isso aqui destacada —, é a hipótese de interposição de **recurso extraordinário** em face de acórdão do Tribunal de Justiça estadual em ADI estadual tendo por objeto lei estadual ou lei municipal contestada em face de norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal (sobre esse modelo, cf. *item 6.8.6*).

■ **agravo:** muito embora a regra da irrecorribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo acima apontada, como visto, o art. 4.º da Lei n. 9.868/99 estabelece que a **petição inicial inepta, não fundamentada** e a

manifestamente improcedente serão **liminarmente indeferidas** pelo **relator**. Contra essa decisão que indeferir a petição inicial cabe o **recurso de agravo** a ser apreciado pelo **Pleno**. Trata-se de agravo a ser interposto nos termos do **art. 317 do RISTF** (previsto no referido dispositivo como *agravo regimental*), no prazo de **5 dias** contados da decisão do relator. Naturalmente, em se tratando de decisão do **Pleno** que não conhece de ação direta de inconstitucionalidade, **não será cabível o agravo**, já que só admissível contra decisão do **relator** que liminarmente indefere a petição inicial (ADI 2.073-AgR-QO, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.10.2000, *DJ* de 24.11.2000). Devemos alertar, conforme já destacamos, que o Novo CPC/2015 especificou a figura do chamado **agravo interno** contra a decisão proferida pelo relator, no prazo de 15 dias (e não mais 5!) e nos parece que, quando entrar em vigor, de fato, nesse ponto, afastará a regra prevista na legislação específica e no regimento interno (cf. arts. 1.021 e 1.070);

■ **não rescindibilidade da decisão proferida**, tudo em razão da **natureza objetiva** do processo de ADI;

não vinculação à tese jurídica (causa de pedir): o STF, ao julgar a ADI, não está condicionado à *causa petendi*, mas ao **pedido do autor**, não se *vinculando a qualquer* tese jurídica apresentada. Devem os Ministros apreciar o pedido de suposta inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, podendo, por conseguinte, decretar a inconstitucionalidade da norma por fundamentos diversos (STF, *RTJ* 46/352).

Nessa hipótese, contudo, entendemos que a regra contida no **art. 10 do CPC/2015** (Lei n. 13.105/2015, com *vacatio legis* de 1 ano) deve ser observada. Conforme exposto, **o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar**, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Essa observância do contraditório, mesmo em processo objetivo, parece bastante interessante, sempre na busca da melhor interpretação a ser dada pela Corte (resta aguardar como o STF interpretará essa questão — **pendente**).

■ 6.7.1.16. A figura do “*amicus curiae*” (ADI e demais ações)

■ 6.7.1.16.1. Regras gerais

Entendemos importante analisar tema que vem ganhando destaque nos concursos públicos: a figura do *amicus curiae* no processo objetivo do controle concentrado de constitucionalidade.

Conforme esclareceu o Ministro Celso de Mello, “o pedido de intervenção assistencial, ordinariamente, não tem cabimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade, eis que terceiros não dispõem, em nosso sistema de direito positivo, de legitimidade para intervir no processo de controle normativo abstrato (*RDA* 155/155, 157/266 — ADI 575-PI (AgRg), Rel. Min. Celso de Mello, v.g.)”. Isso porque, continua, “... o processo de fiscalização normativa abstrata qualifica-se como processo de caráter objetivo (*RTJ* 113/22, 131/1001, 136/467 e 164/506-507)” (ADI 2.130-MC/SC, *DJ* de 02.02.2001, p. 145).

Essa regra está expressa no art. 7.º, *caput*, da Lei n. 9.868/99, que veda a “intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”.

No entanto, o art. 7.º, § 2.º, da referida lei estabelece que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

A lei, assim, consagrou a figura do *amicus curiae* ou “amigo da Corte”. A literalidade do dispositivo já traz alguns elementos:

■ **relator:** a admissão ou não do *amicus curiae* será decidida pelo relator, que verificará o preenchimento dos requisitos e a conveniência e oportunidade da manifestação. Destacamos que, mesmo admitido (pelo relator), o Tribunal poderá deixar de referendá-lo, afastando a sua intervenção (nesse sentido, cf. ADI 2.238, *DJ* de 09.05.2002);

■ **a decisão será irrecorrível: de acordo com a literalidade do art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99**, não cabe recurso da decisão interlocutória que admite ou não a presença do *amicus curiae*. Esse entendimento busca

evitar tumulto processual. **Contudo**, alguns Ministros estão aceitando a interposição de recurso para impugnar a decisão de não admissibilidade de intervenção do *amicus* (cf. o Min. Sepúlveda Pertence, que na ADI 2.591 (fls. 18) sustenta o cabimento de agravo — o CPC/2015 passa a chamar o agravo regimental (apelidado de “agravinho”) de “**agravo interno**” — art. 1.021; e o Min. Marco Aurélio, que sustenta o cabimento de embargos de declaração, mas, mantida a decisão de indeferimento, **não** admite o agravo — ADI 3.346, j. 28.04.2009). A atual jurisprudência do STF que permite a impugnação recursal por parte de terceiro, quando denegada sua participação na qualidade de *amicus curiae*, está sendo **revista** pelo STF no julgamento da **ADI 3.396**, com o julgamento suspenso em 10.05.2012. (Lembramos que o CPC/2015, ao prever a figura do *amicus curiae* no art. 138, continua fixando a **irrecorribilidade** da decisão. Devemos, então, aguardar a interpretação a ser dada pelo STF, havendo forte tendência de se confirmar essa viragem jurisprudencial no sentido de não caber mesmo qualquer recurso da decisão que indeferiu o pedido de ingresso — **matéria pendente de julgamento pelo STF** — cf. *item 6.7.1.16.9*);

■ **requisitos:** relevância da matéria e representatividade dos postulantes;
prazo para admissão: vinha fixado no § 1.º do art. 7.º da Lei n. 9.868/99 (*prazo das informações*), que, no entanto, foi **vetado**. Nas razões do veto, o Presidente da República observa que “... eventual dúvida poderá ser superada com a utilização do prazo das informações previsto no parágrafo único do art. 6.º” (Mensagem n. 1.674/99). Trata-se do prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido de informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado (nesse sentido, cf. ADI 1.104). **Entendemos, contudo, que dada a natureza e finalidade do *amicus curiae* esse prazo poderá ser flexibilizado pelo relator, que terá a discricionariedade para aceitar ou não a sua presença no processo objetivo, ainda que após o decurso do aludido prazo, ou, até mesmo, somente para a apresentação de sustentação-oral**, como se verificou na ADPF 46/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, *DJ* de 20.06.2005). O objetivo do instituto do *amicus curiae* é auxiliar a instrução processual. Assim, em um primeiro momento, o STF entendeu como possível a sua admissão no processo até o início do julgamento. Uma vez em curso e já iniciado o julgamento, a presença do *amicus*

curiae deverá ser rejeitada para evitar tumulto processual (nesse sentido, cf. ADI 2.238, *Inf.* 267/STF). Avançando, o STF **mudou o entendimento** e restringiu um pouco mais o momento. A partir do julgamento da **ADI 4.071** AgR/DF (Rel. Min. Menezes Direito, **22.04.2009**, *DJE* de 16.10.2009 e *Inf.* 543/STF), **o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta.** [180](#)

Além desses requisitos expressos na lei, a jurisprudência do STF vem estabelecendo que, uma vez admitido o *amicus curiae*, ele passa a ter direito de:

■ **apresentar sustentação oral I:** “... assinalo, por necessário, que, em face da decisão plenária proferida em questão de ordem suscitada na **ADI 2.777/SP**, Rel. Min. Cezar Peluso (*DJU* de 15.12.2003, p. 5), o ‘amicus curiae’, uma vez formalmente admitido no processo de fiscalização normativa abstrata, tem o direito de proceder à sustentação oral de suas razões, observado, no que couber, o § 3.º do art. 131 do *RISTF*, na redação conferida pela Emenda Regimental 15/2004” (ADI 3.345/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 29.08.2005. Nesse sentido, cf. ADI 3.540, *DJ* de 25.08.2005; ADI 3.498, *DJ* de 09.08.2005; ADPF 73, *DJ* de 08.08.2005; ADPF 46/DF, *DJ* de 20.06.2005; ADI 3.056, *DJ* de 06.06.2005);

■ **apresentar sustentação oral II:** nesse julgamento da ADI 2.777 o Ministro Sepúlveda Pertence, “... considerando que a Lei 9.868/99 não regulou a questão relativa à sustentação oral pelo *amicus curiae*, entendeu que compete ao Tribunal decidir a respeito, através de norma regimental, razão por que, excepcionalmente e apenas no caso concreto, admitiu a sustentação oral. Vencidos os Ministros *Carlos Velloso* e *Ellen Gracie*, que, salientando que a admissão da sustentação oral nessas hipóteses poderia implicar a **inviabilidade de funcionamento da Corte**, pelo eventual excesso de intervenções, entendiam possível apenas a manifestação escrita” (ADI 2.777, *Inf.* 331/STF);

■ **apresentar sustentação oral III:** a tese vencedora que **admite a sustentação oral pelo amicus curiae** está consagrada, como visto, no **art. 131, § 3.º, do Regimento Interno do STF**, nos termos da Emenda

Regimental n. 15, de 30.03.2004, com a seguinte redação: “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2.º do artigo 132 deste Regimento”. O *caput* do art. 132 estabelece que cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15 minutos. Já o seu § 2.º determina que, se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido igualmente entre os do mesmo grupo, se diversamente entre eles não se convencionar;

limites de atuação: porém, conforme anotou o Min. Gilmar Mendes, é preciso deixar enfatizado que o *amicus curiae*, uma vez admitido seu ingresso no processo objetivo, tem direito a ter seus argumentos apreciados pelo Tribunal, inclusive com direito a sustentação oral (Emenda Regimental n. 15/2004, *RISTF*), **mas não tem direito a formular pedido ou de aditar o pedido já delimitado pelo autor da ação** (AC 1.362, j. 05.09.2006).

Continuando, lembramos que o instituto do *amicus curiae* se consolidou no julgamento da ADI 2.130-MC/SC, no voto do Ministro Celso de Mello (*DJ* de 02.02.2001, p. 145), pedindo vênha para destacar as suas principais passagens:

“a admissão de terceiro, na condição de *amicus curiae*, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como **fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte**, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma **perspectiva eminentemente pluralística**, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os **interesses gerais da coletividade** ou que expressem os **valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais**. Em suma: a regra inscrita no art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/99 — que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do *amicus curiae* — tem por precípua finalidade **pluralizar o debate constitucional**” (grifamos);

“... a regra inovadora constante do art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/99, que, em caráter excepcional, **abrandou o sentido absoluto da vedação**

pertinente à intervenção assistencial, passando, agora, a permitir o ingresso de entidade dotada de **representatividade adequada** no processo de controle abstrato de constitucionalidade” (grifamos);

“... entendo que a atuação processual do *amicus curiae* não deve limitar-se à mera apresentação de memoriais ou à prestação eventual de informações que lhe venham a ser solicitadas. Cumpre permitir-lhe, em extensão maior, o exercício de determinados poderes processuais, como aquele consistente no direito de proceder à **sustentação oral** das razões que justificaram a sua admissão formal na causa. Reconheço, no entanto, que, a propósito dessa questão, existe decisão monocrática, em sentido contrário, proferida pelo eminente Presidente desta Corte, na Sessão de julgamento da ADI 2.321-DF (medida cautelar)”;

assim, continua o ilustre Ministro, o STF, ao admitir a figura do *amicus curiae*, nas hipóteses previstas na lei e de acordo com a jurisprudência que se vem firmando, “... não só garantirá **maior efetividade** e atribuirá **maior legitimidade às suas decisões**, mas, sobretudo, **valorizará**, sob uma perspectiva eminentemente **pluralística**, o sentido **essencialmente democrático dessa participação processual**, enriquecida pelos elementos de informação e pelo acervo de experiências que o *amicus curiae* poderá transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um processo — como o de controle abstrato de constitucionalidade — cujas **implicações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável importância e de inquestionável significação**”.

■ 6.7.1.16.2. É possível a admissão do “*amicus curiae*” na ADC?

SIM.

Essa questão parece bastante pertinente, especialmente diante do veto do § 2.º do art. 18 da Lei n. 9.868/99.

De fato, na mesma linha do art. 7.º, *caput*, o art. 18, *caput*, que também não foi vetado, veda a intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade.

O § 2.º do art. 18 tinha a mesma redação dada ao § 2.º do art. 7.º, o qual, por

sua vez, não foi vetado, nos seguintes termos:

“§ 2.º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

Então, temos a seguinte situação: o dispositivo legal que admitia a figura do *amicus curiae* foi vetado para a ADC (ação declaratória de constitucionalidade), não o sendo para a ADI (ação direta de inconstitucionalidade).

Como poderemos demonstrar melhor no *item 6.7.1.17* (Efeitos da decisão), ADI e ADC são **ações dúplices** ou **ambivalentes**, ou seja, são ações “com sinais trocados”, já que a procedência de uma implica a improcedência da outra.

Essa tendência vinha sendo percebida na jurisprudência do STF (Rcl AgR-QO 1.880 — *Inf. 289/STF*), estando praticamente consolidada na **Reforma do Judiciário**, EC n. 45/2004. Isso porque os legitimados para as ações e os efeitos da decisão passaram a ser os mesmos. A única diferença ainda existente está no objeto da ADC, que continua sendo exclusivamente a **lei federal** (diferentemente da ADI, que tem por objeto tanto a lei federal como a estadual e a distrital de natureza estadual). Cabe alertar, contudo, que, na **PEC Paralela do Judiciário** (PEC n. 29-A/2000-SF e 358/2005-CD), o objeto da ADC passa a ser, também, além da lei federal, a estadual e a distrital de natureza estadual, fechando, em definitivo, essa situação de ambivalência. Resta aguardar a sua aprovação!

Diante do exposto, entendemos possível a aplicação, por analogia, da regra que admite o *amicus curiae* na ADI (art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99) para a ADC. Portanto, admissível, com as ressalvas já apresentadas, a figura do *amicus curiae* na **ação declaratória de constitucionalidade**.

Nesse sentido, o próprio Presidente da República já havia se posicionado nas razões do veto do art. 18, § 2.º (Mensagem n. 1.674/99): “o veto ao § 2.º constitui consequência do veto ao § 1.º. **Resta assegurada, todavia, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação sistemática, admitir no processo da ação declaratória a abertura processual prevista para a ação direta no § 2.º do art. 7.º**”.

■ 6.7.1.16.3. Cabe “*amicus curiae*” na ADPF?

SIM.

O art. 6.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99 tem a seguinte redação: “poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por **requerimento dos interessados no processo**”.

Dessa forma, observa-se que não há, no caso, dispositivo explícito tratando da figura do *amicus curiae*. **Excepcionalmente**, entretanto, o STF vem admitindo a sua presença, aplicando, por analogia, o art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99, desde que se demonstrem a **relevância da matéria** e a **representatividade dos postulantes**.

Na **ADPF 46/DF**, o Ministro Marco Aurélio posicionou-se pela sua admissibilidade, porém, como exceção à regra geral: “... é possível a aplicação, por analogia, ao processo revelador de arguição de descumprimento de preceito fundamental, da Lei n. 9.868/99, no que disciplina a intervenção de terceiro. Observe-se, no entanto, que a participação encerra exceção...” (*DJ* de 20.06.2005, p. 7).

Na **ADPF 73/DF**, o Ministro Relator, Eros Grau, aceitou a figura do *amicus curiae* nos seguintes termos:

“DECISÃO: (PET SR-STF n. 87.857/2005). Junte-se. 2. A Conectas Direitos Humanos requer sua admissão na presente ADPF, na condição de *amicus curiae* (§ 2.º do artigo 6.º da Lei n. 9.882/99). 3. Em face da relevância da questão, e com o objetivo de pluralizar o debate constitucional, aplico analogicamente a norma inscrita no § 2.º do artigo 7.º da Lei n. 9.868/99, admitindo o ingresso da peticionária, na qualidade de *amicus curiae*, observando-se, quanto à sustentação oral, o disposto no art. 131, § 3.º, do *RISTF*, na redação dada pela Emenda Regimental n. 15, de 30.03.2004. Determino à Secretaria que proceda às anotações. Publique-se. Brasília, 1.º de agosto de 2005” (*DJ* de 08.08.2005, p. 27).

Portanto, também com as ressalvas já expostas, concordamos que, excepcionalmente e desde que configuradas as hipóteses de cabimento, admitida

será a presença do *amicus curiae* na ADPF (nesse sentido, confira: **ADPF 205**, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 16.02.2011, *DJE* de 24.02.2011; **ADPF 132**, Rel. Min. Carlos Britto, decisão monocrática, j. 29.04.2009, *DJE* de 07.05.2009 e, ainda, **ADPF 33** e **ADPF 183**).

■ 6.7.1.16.4. Cabe “*amicus curiae*” na ADO?

SIM.

O art. 12-E da Lei n. 9.868/99, incluído pela Lei n. 12.063/2009, determina sejam aplicadas, ao procedimento da **ação direta de inconstitucionalidade por omissão**, no que couber, “as disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta Lei”.

Assim, uma vez que a previsão do *amicus curiae* para a ADI consta da referida Seção (art. 7.º, § 2.º) e sendo compatível com a ação em análise, entendemos **perfeitamente possível a admissão de *amicus curiae* na ADO**, buscando a pluralização do debate.

Ainda, o art. 12-E, § 1.º, da referida lei estabelece que os demais titulares da ADO poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais, o que, em nosso entender, na medida em que, na hipótese, não propuseram a ação, serão considerados *amicus curiae*.

■ 6.7.1.16.5. Cabe “*amicus curiae*” na IF (representação interventiva)?

SIM.

O art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011 permite sejam autorizadas, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de **interessados no processo**, utilizando a mesma nomenclatura (“interessados no processo”) do art. 6.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99, que fundamenta a possibilidade do *amicus curiae* na ADPF.

Assim, de acordo com os precedentes utilizados para a ADPF, parece razoável aceitar, excepcionalmente, e nos termos do art. 7.º, § 2.º (ADI), aqui aplicado por analogia, o *amicus curiae* na representação interventiva (art. 36, III).

■ 6.7.1.16.6. Outras hipóteses de cabimento

Em interessante trabalho,^{[181](#)} Gustavo Santana Nogueira, além das situações já analisadas, identifica outras hipóteses de cabimento do *amicus curiae*, não desenvolvidas neste estudo em razão de nosso objetivo, mas que devem ser observadas especialmente para as provas de direito processual civil:

art. 31 da Lei n. 6.385/76 — processos de interesse da CVM;

art. 118 da Lei n. 12.529/2011 — nos processos judiciais em que se discuta a aplicação da referida Lei n. 12.529/2011, que, dentre outras providências, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente;

art. 482, § 3.º, do CPC/73 (art. 950, § 3.º, do CPC/2015) — controle difuso de constitucionalidade;

art. 14, § 7.º, da Lei n. 10.259/2001 — no âmbito dos Juizados Especiais Federais.^{[182](#)}

Podemos lembrar, ainda, duas importantes hipóteses de *amicus curiae* que são brevemente retomadas no estudo da “repercussão geral” (*item 11.8.1.3*) e da súmula vinculante (*item 11.14*):

art. 3.º, § 2.º, da Lei n. 11.417/2006 — procedimento de edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF;

art. 543-A, § 6.º, do CPC/73, introduzido pela Lei n. 11.418/2006 — análise da repercussão geral pelo STF no julgamento do recurso extraordinário (cf. arts 1.035, § 4.º, e 1.038, I, do CPC/2015).

Finalmente, destacamos uma previsão bastante ampliada do instituto do

amicus curiae nos termos do art. 138 do CPC/2015, que o admite para as causas em geral, desde que se demonstre a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Além disso, conforme estudaremos no item seguinte, a previsão explícita e geral é de que o *amicus curiae* poderá ser **pessoa natural**.

■ **6.7.1.16.7. Parlamentar pode ser admitido no processo como “amicus curiae”? (Novidade mais ampla introduzida pelo CPC/2015 — Lei n. 13.105/2015)**

SIM.

Depois de muito pensar, concordamos com importante e arrojada decisão de **Edson Alfredo Smaniotto**, à época Desembargador do TJDF e relator nos autos da ADI 2004.00.2.008459-7 (decisão em 30.09.2005).

Segundo relata, o parlamentar requer a habilitação no processo como *amicus curiae*, já que foi autor do projeto de lei objeto da ADI, o que, em certa medida, como representante de determinada categoria, por si, uma vez demonstrada a relevância da matéria, já seria suficiente para a sua admissão no processo enquanto “amigo da corte”.

Em suas palavras, avançando “numa análise mais aproximada, tem-se que o postulante, parlamentar, foi designado por via eleitoral para desempenhar função política na democracia representativa sobre a qual se funda o regime democrático instituído no país (CF, art. 1.º), e nesta condição, desenvolve e materializa a cidadania e o direito de representatividade do povo, verdadeiro titular do poder. Sua postulação no processo se dará *erga omnes*”.

Assim, em nosso entender, desde que fique demonstrado que o parlamentar atua como “representante ideológico” de uma coletividade (**representatividade adequada**), e não em busca de interesse individual egoístico, perfeitamente possível a sua admissão como *amicus curiae* (o tema precisa ser mais bem explicitado pelo STF — *pendente*). [183](#)

Cabe apenas alertar, contudo, que o STF **não vem admitindo** o ingresso de

pessoa física como *amicus curiae*, destacando-se, nesse sentido, o voto do Min. Cezar Peluso na **ADI 4.178/GO**:

“... 4. Não assiste razão ao pleito de (...), que requerem admissão na condição de *amici curiae*. É que os requerentes são **pessoas físicas**, terceiros concretamente interessados no feito, **carecendo do requisito de representatividade** inerente à intervenção prevista pelo art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, o qual, aliás, é explícito ao admitir somente a manifestação de outros ‘órgãos ou entidades’ como medida excepcional”.

Finalmente, devemos deixar consignado que o *Novo Código de Processo Civil*, aprovado, em uma visão mais ampla, passa a admitir a **pessoa física** como *amicus curiae*, nos seguintes termos:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de **pessoa natural** ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias da sua intimação.

§ 1.º A intervenção de que trata o *caput* não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3.º.

§ 2.º Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3.º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas”.

■ 6.7.1.16.8. Natureza jurídica do “*amicus curiae*”

Do ponto de vista burocrático, o STF, ao fazer a anotação no processo e indicar o andamento na Internet, fala em “**parte interessada**”, quando admitido o *amicus curiae*.

O Ministro Maurício Corrêa, no julgamento da ADI 2.581 AgR/SP, chegou a

afirmar que o *amicus curiae* atua como “colaborador informal da Corte”, não configurando, “... tecnicamente, hipótese de intervenção *ad coadjuvandum* (AGRA DI 748-RS, Celso de Mello, DJ de 18.11.1994). Assim, como **mero colaborador informal**, o *amicus curiae* não está legitimado para recorrer das decisões proferidas em ação direta” (DJ de 18.04.2002).

O Ministro Celso de Mello, conforme destacamos no julgamento da ADI 2.130, referiu-se a uma **“intervenção processual”**.

O art. 131, § 3.º, do Regimento Interno do STF, nos termos da Emenda Regimental n. 15, de 30.03.2004, passou a admitir uma declarada hipótese de **intervenção de terceiros**.

É claro que a sua natureza jurídica é **distinta** das modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC, até em razão da natureza do processo objetivo e abstrato do controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, por todo o exposto, parece razoável falarmos em uma **modalidade sui generis de intervenção de terceiros**, inerente ao processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, com características próprias e muito bem definidas.

■ 6.7.1.16.9. “*Amicus curiae*” pode interpor recurso? Particularidades do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)

O *amicus curiae*, por se tratar de **terceiro estranho à relação processual**, não pode interpor recurso, impugnando o acórdão proferido nas ações de controle concentrado, para discutir a **matéria** em análise no processo objetivo perante o STF (apenas deixamos a informação que o art. 138, § 3.º, do CPC/2015, estabelece que o *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas — IRDC).

Excepcionalmente, porém, a **atual jurisprudência do STF**, que inclusive **está sendo rediscutida**, desprezando a literalidade do art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99, **184 admite** a impugnação da decisão que denega o pedido de intervenção nos autos como *amicus curiae* (**agravo regimental** no prazo de 5

dias — lembramos que o CPC/2015 fala em **agravo interno** — art. 1.021, no prazo de 15 dias — art. 1.070). Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos por *amicus curiae*. Ausência de legitimidade. Interpretação do § 2.º, do art. 7.º, da Lei n. 9.868/99. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. **Exceção apenas para impugnar decisão de não admissibilidade de sua intervenção nos autos.** Precedentes” (**ADI 3.615-ED**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.03.2008, *DJE* de 25.04.2008 — no mesmo sentido, cf. ADI 2.591-ED).

Cabe alertar que o Plenário do STF iniciou o julgamento de **agravo regimental** interposto, por procurador da Fazenda Nacional, contra decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso nos autos na qualidade de *amicus curiae*. O Min. Celso de Mello, relator, em preliminar, conheceu do recurso de agravo com fundamento em precedentes que **permitiram a impugnação recursal por parte de terceiro**, quando denegada sua participação na qualidade de *amicus curiae* (**ADI 3.105 ED/DF**, *DJE* de 23.02.2007; **ADI 3.934 ED-AgR/DF**, *DJE* de 31.03.2011; e **ADI 3.615 ED/PB**, *DJE* de 25.04.2008 — cf. *Inf. 665/STF*). [185](#)

Analisando essa preliminar de cabimento do recurso de agravo regimental (**ADI 3.396**), até o fechamento desta edição o resultado inicial estava em **5 x 4** pelo seu não conhecimento, ou seja, a maioria dos Ministros decidia no sentido do não cabimento de recurso na hipótese de indeferimento do pedido de intervenção como *amicus curiae*.

Dessa forma, em **10.05.2012**, diante da constatação de que referida decisão alteraria a atual jurisprudência do STF, o Plenário decidiu **suspender o julgamento** para aguardar os votos da Min. Cármen Lúcia e do Min. Joaquim Barbosa (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Lembramos que o Min. Joaquim Barbosa se aposentou em 31.07.2014 e *até o fechamento desta edição* ainda não havia tomado posse o novo Ministro Luiz Edson Fachin. Assim, o atual entendimento do STF permanece no sentido de se

admitir a interposição de agravo regimental (“agravo interno” na denominação do CPC/2015) na hipótese de indeferimento do cabimento do pedido de ingresso como *amicus curiae*. Nesses termos, destacamos decisão proferida em **18.12.2014** no julgamento da **ADI 5.022 AgR/RO** (continuamos, contudo, atentos ao julgamento da mencionada ADI 3.396).

■ 6.7.1.17. Efeitos da decisão (ADI genérica)

A ação em comento tem caráter **dúplice** ou **ambivalente**, pois, conforme estabelece o art. 24 da Lei n. 9.868/99, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e, no mesmo passo, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória.

De modo geral, a decisão no controle concentrado produzirá efeitos contra todos, ou seja, **erga omnes**, e também terá efeito retroativo, **ex tunc**, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição. Trata-se, portanto, de **ato nulo**.

No entanto, acompanhando o direito alemão e o português, entre outros, a Lei n. 9.868/99, em seu art. 27, introduziu a técnica da **declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade**. Nesse sentido, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o STF, por maioria qualificada de **2/3** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Ou seja, diante de tais requisitos, o STF poderá dar **efeito ex nunc**. [186](#)

Além da eficácia contra todos (*erga omnes*), já comentada, o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99 dispõe que a decisão também terá **efeito vinculante**.

Em um primeiro momento, antes da posição firmada na jurisprudência do STF e das novidades trazidas pela **EC n. 45/2004**, tínhamos o entendimento de

que esse dispositivo deveria ser interpretado acompanhando o posicionamento do Ministro Sepúlveda Pertence, que dizia ser tal vinculação possível somente nos casos em que, em tese, seria cabível a ADC, devendo o STF assim se pronunciar, sob pena de se dizer mais do que a Constituição estabeleceu.¹⁸⁷

Em relação ao tema, contudo, concluindo o julgamento de questão de ordem em agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Maurício Corrêa, relator — que não conhecera de reclamação ajuizada pelo Município de Turmalina-SP em que se pretendia ver respeitada a decisão proferida pelo STF na ADI 1.662-SP por falta de legitimidade ativa *ad causam* do reclamante —, o STF, por maioria (8 x 3, vencidos os Ministros Moreira Alves, Ilmar Galvão e Marco Aurélio), **declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99**, considerando que a **ação declaratória de constitucionalidade (ADC)** consubstancia uma **ação direta de inconstitucionalidade (ADI)** com sinal trocado, tendo ambas caráter dúplice, sendo os seus efeitos, portanto, semelhantes.¹⁸⁸ Essa interpretação, como veremos a seguir, foi expressamente consagrada com a **Reforma do Judiciário**, EC n. 45/2004, ao dar nova redação ao art. 102, § 2.º, da CF/88.

Logo, para as provas de concurso, adotar o entendimento de que a **declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado**, em **abstrato**, em **tese**, marcada pela **generalidade, impessoalidade e abstração**, faz instaurar um **processo objetivo**, sem partes, no qual inexistente litígio referente a situações concretas ou individuais (RTJ 147/31, Rel. Min. Celso de Mello), tornando os atos inconstitucionais **nulos** e, por consequência, **destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica**, com alcance, de modo vinculado e para todos, sobre os **atos pretéritos**, fazendo com que, para se ter uma ideia da amplitude desses efeitos, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo que tenha “revogado” outro ato normativo (nossa análise neste ponto refere-se à ADI perante o STF, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou distrital, desde que no exercício da competência estadual) provoque o **restabelecimento do ato normativo anterior**. Os efeitos gerais da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, por meio de ADI,

podem ser assim resumidos:

erga omnes;

ex tunc;

vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital.

Excepcionalmente, porém, como exceção à regra geral do princípio da nulidade, tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o STF, por maioria qualificada de **2/3 de seus Ministros**,¹⁸⁹ restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Excepcionalmente, então, os Ministros do STF poderão restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que, na hipótese específica e desde que preencha os requisitos formal (*quorum* **qualificado de 2/3**) e material (**razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**), serão:

erga omnes;

ex nunc; ou **outro momento a ser fixado pelos Ministros do STF, podendo a modulação ser em algum momento do passado, no momento do julgamento, ou para o futuro (efeito prospectivo);**

vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital.

Alertamos que não há necessidade de suspensão da execução da lei ou ato normativo declarado inconstitucional, por decisão definitiva do STF, por meio de resolução do Senado Federal no controle concentrado. Isso porque o **art. 52, X, só se aplica ao controle difuso!**¹⁹⁰

Apenas para sedimentar, transcrevemos a regra trazida no § 2.º do art. 102, constitucionalizando, de uma vez por todas, o caráter dúplice ou ambivalente da ADI e da ADC: “§ 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Conforme vimos no *item 6.7.1.8*, o efeito vinculante atinge somente o **Judiciário** e o **Executivo**, não se estendendo para o Legislativo no exercício de sua função típica de legislar (nem atingindo, conforme sugerimos, as funções atípicas normativas tanto do Judiciário como do Executivo, quando, por exemplo, o Presidente da República edita uma medida provisória), que poderá, inclusive, editar nova lei em sentido contrário à decisão do STF em controle de constitucionalidade concentrado ou edição de súmula vinculante. Entendimento diverso significaria o **“inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição”** (cf. **Rcl 2.617**, *Inf. 386/STF*).

■ 6.7.1.17.1. *Princípio da parcelaridade*

O **princípio da parcelaridade** aplica-se ao controle concentrado. Isso significa que o STF pode julgar parcialmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, expurgando do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial, como veremos ao estudar o processo legislativo (art. 66, § 2.º).

Isso porque, e já adiantando a matéria, o Presidente da República, ao vetar determinado projeto de lei (controle de constitucionalidade prévio ou preventivo, realizado pelo Executivo), só poderá fazê-lo **integralmente** (veto de todo o projeto de lei), ou **parcialmente**; nesta última hipótese, porém, o veto só poderá ser de **texto integral** de artigo, parágrafo, inciso ou alínea (art. 66, § 2.º, da CF).

Por outro lado, o Judiciário, ao realizar o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade, poderá expungir do texto normativo uma expressão, uma só palavra, uma frase, não havendo necessidade de declarar inconstitucional um texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, como acontece com o controle realizado pelo Chefe do Executivo.

Trata-se de interpretação conforme com redução de texto, verificada, por exemplo, na ADI 1.227-8, suspendendo a eficácia da expressão “desacato” do art. 7.º, § 2.º, do Estatuto dos Advogados.

■ 6.7.1.17.2. **Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto**

Muitas vezes, o STF pode declarar que a mácula da inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a **interpretação conforme**, pela qual não se configura a inconstitucionalidade.

Importante notar que em hipótese alguma poderá o STF funcionar como *legislador positivo*. A interpretação conforme só será admitida quando existir um **espaço para a decisão** do Judiciário, deixado pelo Legislativo. A interpretação não cabe quando o sentido da norma é **unívoco**, mas somente quando o legislador deixou um campo com diversas interpretações, cabendo ao Judiciário dizer qual delas se coaduna com o sentido da Constituição. O Judiciário, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada lei, deve sempre atuar como **legislador negativo**, sendo-lhe vedado, portanto, instituir norma jurídica diversa da produzida pelo Legislativo.

■ 6.7.1.17.3. **Efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Necessidade de impugnação de todo o “complexo normativo”**

O controle concentrado por meio da ADI é marcado pela generalidade, impessoalidade e abstração e faz instaurar um **processo objetivo**, sem partes, no qual inexistente litígio referente a situações concretas ou individuais (*RTJ* 147/31, Rel. Min. Celso de Mello).

Nesse sentido, a declaração de inconstitucionalidade reconhece a **nullidade** dos atos inconstitucionais e, por consequência, a inexistência de qualquer carga de eficácia jurídica. Assim, dentre tantos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo que tenha “revogado” outro ato normativo (*nossa análise nesse ponto refere-se à ADI perante o STF, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou distrital, desde que no exercício da competência estadual*) provoca o restabelecimento do ato normativo anterior, quando a decisão tiver efeito retroativo.

O STF vem utilizando a expressão **“efeito repristinatório”** (cf. ADI 2.215-

PE, medida cautelar, Rel. Min. Celso de Mello, *Inf.* 224/STF) da declaração de inconstitucionalidade. Isso porque, se a lei é nula, ela nunca teve eficácia. Se nunca teve eficácia, nunca revogou nenhuma norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido supostamente “revogada” continua tendo eficácia. Eis o efeito repristinatório da decisão.

Não se pode confundir (embora o STF utilize sem muito critério as expressões) “efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade” com “repristinação da norma”. No primeiro caso temos o restabelecimento da lei anterior porque, se a lei objeto do controle é inconstitucional e, assim, nula, ela nunca teve eficácia, portanto, nunca revogou nenhum outro ato normativo. No segundo, qual seja, na repristinação, nos termos do art. 2.º, § 3.º, da **LINDB** (*Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro* — Decreto-lei n. 4.657/42), [191](#) salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, ou seja, precisa de pedido expresso desta terceira lei (que revoga a lei revogadora da lei inicial).

Avançando essa regra geral do efeito repristinatório, contudo, podemos estar diante de situação de revogação da norma anterior mesmo que o STF reconheça a inconstitucionalidade de determinada norma posterior.

Para recordar, os efeitos gerais da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, por meio de ADI, são: *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, podendo ser dado efeito *ex nunc*, ou a partir de outro momento que venha a ser fixado (exceção à regra geral do princípio da nulidade), desde que a votação tenha sido por 2/3 dos Ministros, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Ocorrendo a **modulação dos efeitos da decisão**, nesse caso, parece-nos que a lei (objeto do controle) vai sim ter a eficácia de revogar a lei anterior. Isso porque, se a decisão reconhece efeitos da referida norma, temos de aceitar a sua existência, validade e, durante o período que o STF determinar, a sua **eficácia**, gerando, dentre tantos efeitos, a natural revogação de lei em sentido contrário ou se expressamente assim estabelecer.

Por fim, destacamos um aspecto formal importante. Se o legitimado ativo da

ADI objetivar que a Suprema Corte analise a inconstitucionalidade da lei que vai voltar a produzir efeitos (em razão do efeito repristinatório da decisão), terá de, expressamente, fazer o pedido de apreciação da referida lei, sob pena de o STF não poder, de ofício, apreciá-la e, para piorar, **não conhecer** da ação direta ajuizada. Nesse sentido:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: **efeito repristinatório**: norma anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade da norma objeto da causa, ter-se-ia a **repristinação** de preceito anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. Neste caso, **e não impugnada a norma anterior, não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade**” (ADI 2.574, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 02.10.2002, DJ de 29.08.2003).

“EMENTA: Fiscalização normativa abstrata — Declaração de inconstitucionalidade em tese e **efeito repristinatório**. A declaração de inconstitucionalidade *in abstracto*, considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente (*RTJ* 120/64 — *RTJ* 194/504-505 — ADI 2.867/ES, v.g.), importa em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo abstrato. É que a lei declarada inconstitucional, por incidir em absoluta desvalia jurídica (*RTJ* 146/461-462), não pode gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela anteriores. **Lei inconstitucional, porque inválida (RTJ 102/671), sequer possui eficácia derogatória**. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos atos estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional. Doutrina. Precedentes (ADI 2.215-MC/PE, Rel. Min. Celso de Mello, *Informativo*/STF n. 224, v.g.). Considerações em torno da questão da eficácia repristinatória indesejada e da **necessidade de impugnar os atos normativos, que, embora revogados, exteriorizem os mesmos vícios de inconstitucionalidade que inquinam a legislação revogadora**. Ação direta que impugna, não apenas a Lei estadual n. 1.123/2000, mas, também, os diplomas legislativos que, versando matéria idêntica (serviços lotéricos),

foram por ela revogados. Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de **todo o complexo normativo**. Correta formulação, na espécie, de **pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade tanto do diploma abrogatório quanto das normas por ele revogadas**, porque também eivadas do vício da ilegitimidade constitucional. Reconhecimento da inconstitucionalidade desses diplomas legislativos, não obstante já revogados” (ADI 3.148, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.12.2006, *DJ* de 28.09.2007).

Por todo o exposto, fica claro que, em eventual controle normativo abstrato a ser instaurado, deverá haver a impugnação de todo o **“complexo normativo”**, de toda a **“cadeia normativa”**, tanto as normas revogadoras como as normas revogadas.

E qual o limite temporal de impugnação da cadeia normativa?

De acordo com o voto do Min. Gilmar Mendes, na **ADI 3.660**, a necessidade de indicação dos atos que compõem a “cadeia normativa” se limita até o **advento da nova Constituição**. Pedimos vênias para transcrever a importante passagem de seu voto:

“... é preciso levar em conta que o processo do controle abstrato de normas destina-se, fundamentalmente, à aferição da constitucionalidade de normas pós-constitucionais (ADI n. 2, Rel. Paulo Brossard, *DJ* 2.2.92). Dessa forma, eventual colisão entre o direito pré-constitucional e a nova Constituição deve ser simplesmente resolvida segundo princípios de direito intertemporal (*Lex posterior derogat priori*). Assim, conjugando ambos os entendimentos professados pela jurisprudência do Tribunal, a conclusão não pode ser outra senão a de que a **impugnação** deve **abranger apenas a cadeia de normas revogadoras e revogadas até o advento da Constituição de 1988**” (voto do Min. Gilmar Mendes na ADI 3.660, j. 13.03.2008, Plenário, *DJE* de 09.05.2008).

■ **6.7.1.17.4. Efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade** [192](#)

■ **6.7.1.17.4.1. Coisa julgada inconstitucional. S. 343/STF. Rescisória (art.**

COLISÃO		
■ Segurança jurídica ■ Autoridade do Poder Judiciário ■ Estabilidade das relações sociais	X	■ Força normativa da Constituição ■ Princípio da máxima efetividade das normas constitucionais ■ Isonomia: a aplicação assimétrica viola um referencial normativo que dá sustentação a todo o sistema

De modo geral, vimos, a declaração de inconstitucionalidade no **controle concentrado** tem efeitos retroativos (*ex tunc*), declarando-se a **nulidade** da lei.

Pode ser afirmado, então, por regra, que a lei inconstitucional nunca produziu efeitos, até porque a sentença declaratória restitui os fatos ao *statu quo ante*. Esse reconhecimento gera diversas consequências.

Uma **primeira** seria o “efeito repristinatório”, já estudado.

Outra consequência seria a conveniência, aprimorada pelo STF, de se aplicar a técnica da **modulação dos efeitos da decisão** diante de situações particulares, especialmente se reconhecidas por decisões judiciais transitadas em julgado.

Nesse contexto, há necessidade de se respeitar a **coisa julgada**, exceto na hipótese de **matéria penal** (art. 5.º, XL, da CF/88), que, a qualquer tempo, permite a revisão criminal (veja que neste caso já houve pelo constituinte originário uma “ponderação de interesses”).

Assim, expressamente, o texto não faz outra ressalva, tendo erigido a coisa julgada como valor fundamental.

Processualmente, a sua **desconstituição** deve seguir a **regra processual**, qual seja, pela utilização da **ação rescisória** dentro do prazo decadencial de 2 anos, sendo que, findo tal prazo, fala-se em **coisa soberanamente julgada**, não mais

podendo a matéria ser revista.

Podem ser lembradas, contudo, técnicas de “relativização” ou, utilizando uma terminologia mais adequada, de “**desconstituição**” da coisa julgada. Vejamos:

a decisão **transitada em julgado** se funda em lei que vem a ser, em momento posterior, declarada inconstitucional;

a decisão transitada em julgado afronta outros valores da Constituição (cf. *item 6.7.1.17.4.4*).

No primeiro caso, estamos diante da denominada “**sentença inconstitucional**”, [193](#) qual seja, aquela que considera lei válida e que, por decisão futura do STF, em **controle concentrado**, vem a ser declarada inconstitucional, ou o contrário.

Nessas hipóteses, parece razoável que se aceite o ajuizamento de **ação rescisória**, nos termos do art. 485, V, [194](#) do CPC/73, lembrando, do ponto de vista formal, o entendimento do STF que exige a juntada de (novo) instrumento de mandato específico, mesmo que conste esse poder no mandato originário, já que estaremos diante de ação autônoma e com caráter excepcional (nesse sentido, cf.: AR 2.236-ED, AR 2.239-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.06.2010, Plenário, *DJE* de 03.09.2010; e AR 2.156, AR 2.183 e AR 2.202, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.08.2010).

Para este estudo, sustentamos que o cabimento da rescisória dar-se-á tanto no caso de declaração de **constitucionalidade** como no de **inconstitucionalidade** em controle concentrado, com efeito *erga omnes* e *ex tunc*, em razão do efeito dúplice ou ambivalente das ações. A inconstitucionalidade da sentença está na desconformidade de interpretação dada à lei. [195](#)

Contudo, **deverá ser respeitado o prazo decadencial de 2 anos para o seu ajuizamento** e, ainda, a controvérsia sobre a matéria deverá ser necessariamente **constitucional** e não meramente infraconstitucional, para, desta feita, afastar a incidência da S. 343/STF. [196](#)

Transcorrido *in albis* o prazo decadencial de 2 anos sem o ajuizamento da ação rescisória, não mais se poderá falar em desconstituição da coisa julgada individual pela técnica da ação rescisória, mesmo que em controle concentrado

venha a ser declarada a inconstitucionalidade de lei com efeitos *ex tunc*.

Segundo Gilmar Mendes, trata-se de “... proteção ao ato singular, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no **plano normativo** (*Normebene*) e no **plano do ato singular** (*Einzelaktebene*) mediante a utilização das *fórmulas de preclusão*”. E completa, com bastante propriedade: “... somente serão afetados pela declaração de inconstitucionalidade com eficácia geral os atos ainda suscetíveis de revisão ou impugnação”. [197](#)

Esse tema já foi discutido pelo STF no **AI 460.439 AgR/DF** (*Inf.* 397 e 436/STF, *DJ* de 09.03.2007, Ata n. 6/2007) e na **Rcl 2.600** (*Inf.* 440/STF, *DJ* de 03.08.2007), sendo acatada a tese de **afastamento da S. 343/STF** sem, todavia, ser resolvida a questão da contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória.

A discussão sobre essa problemática foi iniciada no julgamento da Rcl 2.600, em *obter dictum*, porém o STF, naquele momento, não chegou a enfrentar o prazo para o ajuizamento da rescisória.

Para este estudo, entendemos, **do ponto de vista doutrinário** (posicionamento assumido em nossa tese de doutorado, USP), que o prazo decadencial tem de ser contado do **trânsito em julgado da decisão individual** e foi adotado pela jurisprudência do STF, como se observa abaixo, em julgamento posterior ao da Rcl 2.600 (mas antes da vigência do Novo CPC/2015). [198](#)

Adotar o cabimento da rescisória a partir da nova posição do STF transitada em julgado, em nosso entender, por se tratar de decisão futura e incerta e que poderia ocorrer após vários anos do trânsito em julgado da decisão individual, caracterizaria uma indesejável perpetuação da “**espada de Dâmocles**” [199](#) e violação aos princípios constitucionais da **segurança jurídica** e **autoridade das decisões do Poder Judiciário**.

Isso posto, a única maneira de se desconstituir a coisa julgada **após o prazo decadencial** da ação rescisória será por outra técnica, qual seja, a da **desconsideração à luz do princípio da proporcionalidade** e limitada às

sentenças que **ferirem outros valores constitucionais de igual hierarquia** ao da **segurança jurídica e estabilidade das decisões** e ficar reconhecido, nessa **ponderação de interesses**, que devam ser afastados. O cabimento de rescisória deve respeitar, necessariamente, o prazo decadencial de 2 anos, enfatize-se.

Esse nosso entendimento fica fortalecido com a decisão proferida no **RE 328.812-ED** (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.03.2008, *DJE* de 02.05.2008 e *Inf.* 497/STF). Segundo o voto do Min. Gilmar Mendes, relator, a **controvérsia de interpretação de lei** é muito diferente da **controvérsia de interpretação constitucional**, tendo em vista que nas decisões proferidas pelo STF se verifica uma particular forma de **concretização constitucional**.

Assim, diante da colisão verificada (*vide* quadro), deve-se optar, nessa ponderação de valores, pela preservação da **força normativa da Constituição**, do **princípio da máxima efetividade das normas** e da ideia de **isonomia**, já que a aplicação assimétrica de decisões da corte significaria uma insuportável instabilidade (mais grave que a instabilidade gerada pela ação rescisória) e, conseqüentemente, um fortalecimento das decisões dos tribunais inferiores em relação ao STF, que é o intérprete máximo da Constituição e que, por último, fixa a sua força normativa.

Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes deixa muito claro que o **prazo decadencial de 2 anos deverá ser respeitado**, fortalecendo, assim, a nossa posição teórica, defendida anteriormente. [200](#)

■ 6.7.1.17.4.2. **Explicitação da amplitude da S. 343/STF. “Leading Case”:** **RE 590.809 (j. 22.10.2014). CPC/73 e CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)**

O tema em análise, especialmente a **amplitude da S. 343/STF**, veio a ser rediscutido pelo STF no julgamento do **RE 590.809** (22.10.2014).

No caso concreto, analisava-se a possibilidade de ação rescisória em razão de mudança de entendimento pela Corte sobre matéria constitucional. O acórdão que estava em discussão consolidou, em 02.03.2004, o entendimento de que o contribuinte tem o direito aos créditos presumidos de IPI quando da aquisição de

insumos e matérias-primas isentos, não tributados e sujeitos à alíquota zero.

Essa tese firmada, favorável ao contribuinte, **vigorou até 2007**, destacando-se o seguinte precedente: **RE 212.484**, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 05.03.98, Plenário, *DJ* de 27.11.98 (cf., também: RE 350.446/PR; RE 353.668/PR e RE 357.277/RS).

Em **25.06.2007**, contudo, o STF **alterou diametralmente** o seu posicionamento e passou a decidir no sentido de não mais se reconhecer o direito ao referido crédito. Essa mudança de interpretação, naturalmente, beneficiou a Fazenda Pública, contrariando os interesses dos contribuintes.^{[201](#)}

A partir dessa nova posição, a Fazenda Pública iniciou um trabalho judicial objetivando a cobrança de valores não recolhidos, muitos amparados por sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante o ajuizamento de **ação rescisória**, com base no art. 485, V, CPC/73, sustentando o afastamento da S. 343/STF, conforme vimos no item anterior.

O STF, por maioria, contudo, no tocante ao entendimento que até então vigora no sentido de não aplicar a referida súmula, firmou um **novo direcionamento**, resgatando a aplicação da S. 343/STF e, assim, não mais admitindo, pura e simplesmente, a rescisória pelo fato de ter havido mudança em sua jurisprudência.

Basicamente, procurou-se **não banalizar o direito fundamental da coisa julgada**,^{[202](#)} destacando-se os **princípios da segurança jurídica** e da **estabilidade das relações sociais** e, assim, nos termos das situações fáticas do caso concreto, a **manutenção da S. 343/STF** e, portanto, o afastamento da rescisória, preservando-se o acórdão rescindendo **mesmo diante da alteração do entendimento da Corte**. Vejamos parte do voto do Relator e a ementa do acórdão:

“A rescisória deve ser reservada a **situações excepcionalíssimas**, ante a **natureza de cláusula pétrea** conferida pelo constituinte ao **instituto da coisa julgada**. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil (1973), incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, **não se trata de**

defender o afastamento da medida instrumental — a rescisória — presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com **óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada**” (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014, Plenário, DJE de 24.11.2014, fls. 10).

“EMENTA: “AÇÃO RESCISÓRIA *VERSUS* UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA — VERBETE N. 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete n. 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, **inexistente controle concentrado de constitucionalidade**, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, **óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda**” (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014, Plenário, DJE de 24.11.2014).

Estamos diante de preocupação muito evidente no **Novo Código de Processo Civil**, que teve o cuidado de encontrar instrumentos para uma maior **valorização dos precedentes**, propugnando não somente pela **estabilidade da jurisprudência**, mas, especialmente, por sua **integridade** e **coerência**, verdadeiros **vetores principiológicos** a partir de uma concepção de **dignidade da pessoa humana**, considerando os princípios da **segurança jurídica**, da **proteção da confiança** e da **isonomia** (cf. arts. 926, *caput*, [203](#) e 927, §§ 3.º e 4.º, [204](#) e aprofundamento no *item 6.6.5.2*).

Tem-se, por conseguinte, uma inegável **valorização do entendimento firmado na S. 343/STF** que afasta o uso irracional da rescisão de decisões transitadas em julgado.

Lendo o acórdão, em análise, inclusive a sua ementa, parece que o STF adota a perspectiva por nós sugerida no âmbito acadêmico (nossa tese de doutorado — USP), no sentido de só se permitir a rescisória da decisão concreta anterior se o novo posicionamento tiver sido firmado em **ação de controle concentrado** com

efeito *erga omnes* e vinculante e dentro do prazo decadencial de 2 anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão individual (o que também pode ser observado em razão de edição de **súmula vinculante** a reconhecer a nulidade do ato normativo que fundamentou a decisão de mérito transitada em julgado).

Esse entendimento, naturalmente, não poderá ser o mesmo nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, mesmo na hipótese de edição de resolução pelo Senado Federal.

Isso porque, no controle difuso, conforme vimos, os efeitos da decisão operam para as partes do processo e, no caso da resolução do Senado Federal, os seus efeitos serão para o futuro (*ex nunc*) e atingirão, então, em razão da suspensão *erga omnes*, apenas as decisões sem trânsito em julgado.

No controle concentrado, por outro lado, ou mesmo em razão de edição de súmula vinculante, reconhecendo-se a nulidade do ato normativo, os efeitos serão para todos e, por regra, com efeito retroativo.

Neste caso, diferentemente do controle difuso, conforme escrevemos em nossa tese de doutorado, não se trata de eficácia natural da sentença *erga omnes*, que, em tese, poderia ser afastada pela demonstração de prejuízo jurídico individual. No fundo, trata-se de **extensão erga omnes da coisa julgada, pro et contra**, e mesmo sem a participação de terceiros, até porque forte é a ideia de substituição processual da coletividade pelos legitimados do art. 103 da CF/88.

Analisando o **Novo Código de Processo Civil/2015**, percebemos uma melhora na redação do dispositivo a justificar o cabimento da ação rescisória conforme se observa pelo quadro abaixo:

CÓDIGO DE PROCESSO DE 1973	NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
■ Art. 485, V: “A sentença de mérito,	■ Art. 966, V: “A decisão de mérito,

transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei	transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica
---	---

No **CPC/2015**, não houve explicitação sobre a técnica em análise, mas, sem dúvida, entendemos ainda cabível o mecanismo de desconstituição da coisa julgada se houver mudança na jurisprudência do STF e definição do novo sentido da norma jurídica constitucional a traduzir a força normativa da Constituição.

Devemos deixar bem claro o que dissemos acima também para o CPC/2015: concordamos com a posição do STF no precedente em análise de só admitir a utilização da rescisória, como técnica de desconstituição, em **situações excepcionalíssimas** e se a mudança de interpretação se deu em **controle concentrado** ou em razão de edição de **súmula vinculante**. Jamais podemos pensar o afastamento da S. 343/STF (e, no caso, admitir a rescisória), em razão de alteração da interpretação dada à lei ou ao ato normativo em controle difuso de constitucionalidade, como no julgamento de recursos extraordinários, mesmo nas hipóteses daqueles definidos como **“repetidos”** (arts. 1.036 e segs. do CPC/2015). Isso porque, conforme explicitamos no *item 6.6.5*, **o STF não adotou a tese da abstrativização do controle difuso**.

Passamos, então, a analisar o instrumento do “embargos rescisórios”, bem como as novidades introduzidas pelo CPC/2015. Vejamos.

■ **6.7.1.17.4.3. Arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73: “embargos rescisórios”. Como ficou no Novo CPC/2015 (arts. 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5.º a 8.º)?**

Agora, podemos analisar a regra contida nos arts. 741, parágrafo único (redação dada pela Lei n. 11.232/2005, assim como a redação que lhe conferia a MP n. 2.180-35), e 475-L, § 1.º, ambos do CPC/73, para, em seguida, analisar o Novo CPC/2015.

Por um lado, poder-se-ia dizer que a novidade é **inconstitucional**, por violação ao princípio da **segurança jurídica** e ao da **autoridade do Poder Judiciário**. Mas essa argumentação parece enfraquecer-se diante da solução conferida pelo STF em relação à colisão apontada.

Por outro lado, podemos afirmar ser a **ação rescisória** a única técnica processual estabelecida no sistema brasileiro para, de maneira legítima, desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, previsão em vários dispositivos da CF/88 (cf. arts. 102, I, “j”; 105, I, “e”; 108, I, “b”, e art. 27, § 10, do ADCT).

Referidos dispositivos **legais** (os arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73) não tratam de “relativização” imoderada ou da hipótese de “desconstituição pelo princípio da proporcionalidade”, mas de uma nova técnica (“**embargos rescisórios**”) a afrontar a **regra constitucional da ação rescisória**. Nesse sentido, inconstitucional. [205](#)

Este parece o entendimento a ser adotado pela maioria dos Ministros do STF:

■ **ação rescisória:** único instrumento processual para eventual desconstituição de coisa julgada, **não** se admitindo, assim, *embargos rescisórios* introduzidos nos arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73, nem mesmo o *recurso extraordinário* para o afastamento da garantia da coisa julgada;

prazo decadencial de 2 anos: para o ajuizamento da ação rescisória, único instrumento para a desconstituição da coisa julgada, deverá ser observado, necessariamente, o prazo decadencial de 2 anos.

Contudo, como se verificou, essa discussão está para ser resolvida pelo Pleno do STF no julgamento das **ADIs 3.740 e 2.418 (matéria pendente de julgamento)**, mas já há decisões sinalizando no sentido da inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos processuais (arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73), destacando-se:

“EMENTA: (...) A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RECONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só pode

ser desconstituída mediante ajuizamento de **específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória)** que haja sido **proposta** na fluência do **prazo decadencial** previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da **coisa soberanamente julgada**, insuscetível de ulterior modificação, **ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade**. A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (*RTJ* 87/758 — *RTJ* 164/506-509 — *RTJ* 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes” (**RE 594.350/RS**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.05.2010, *DJe* de 10.06.2010 — cf. íntegra do fundamentado voto no *Inf.* 591/STF — **matéria pendente de julgamento pelo Pleno do STF**).²⁰⁶

Apenas para argumentar o que não concordamos, imaginando que o STF entenda constitucional a utilização desse instrumento de defesa na execução (flexibilizando a perspectiva de hipóteses taxativas para a ação rescisória), sustentamos a necessidade de se observar o prazo decadencial de 2 anos e que deverá ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que constituiu o título executivo (cumprimento de sentença ou execução contra a Fazenda Pública), e não a partir do entendimento do STF. No caso, também, entendemos que esse novo entendimento deverá se dar, necessariamente, em sede de **controle concentrado**, ou em razão de edição de **súmula vinculante**, mas nunca por decisão em controle difuso (pelo fato, já visto, de que o STF não adotou a tese da abstrativização do controle difuso).

E como ficou essa regra no Novo CPC/2015?

Para responder, iniciamos analisando as novidades introduzidas pelo CPC/2015 e apontadas no quadro abaixo:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CPC/73	DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CPC/2015
Art. 475-L: “A impugnação somente poderá versar sobre: II — inexigibilidade do título. § 1.º Para efeito do disposto no inciso II do <i>caput</i> deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”.	Art. 525, § 1.º: “Na impugnação, o executado poderá alegar: III — inexecutabilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1.º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em <i>lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal</i>, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CPC/73	DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA CPC/2015
Art. 741. “Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: II — inexigibilidade do título. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do <i>caput</i> deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”.	Art. 535. “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: III — inexecutibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. § 5.º Para efeito do disposto no inciso III do <i>caput</i> deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em <i>lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal</i>, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6.º No caso do § 5.º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7.º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5.º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8.º Se a decisão referida no § 5.º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória,

	cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.
--	---

A previsão estabelecida nos arts. 525, § 12, e 535, § 5.º (CPC/2015), no tocante à inexigibilidade da obrigação, será verificada se o título estiver fundado em lei que o STF já tenha, **anteriormente ao seu trânsito em julgado**, declarado inconstitucional (arts. 525, § 14, e 535, § 7.º).

O dispositivo em análise estabelece que esse reconhecimento da inconstitucionalidade tenha sido em controle concentrado ou em controle **difuso**.

Devemos alertar que a “contaminação” do título somente será verificada se o reconhecimento **prévio** da inconstitucionalidade pelo STF tiver sido em controle concentrado ou, se no controle difuso, **a execução da lei tiver sido suspensa por resolução do Senado Federal** (art. 52, X). Não podemos admitir que a decisão em caso isolado, sem a referida resolução do SF, possa vincular os juízes e tribunais do país (cf. discussão sobre a não aceitação da tese da abstrativização do controle difuso no *item 6.6.5*).

Nesse ponto, a análise do Novo CPC merece um destaque: a **redação original** do projeto de lei encaminhado para o Senado Federal (**PL 166/2010**) deixava claro que o cabimento dessa tese de impugnação seria possível nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado ou, se no controle **difuso, somente se houvesse suspensão da execução da norma por resolução do Senado Federal** (anteriores ao trânsito em julgado da decisão exequenda).

A redação encaminhada para sanção presidencial decorreu de aprovação de **substitutivo da Câmara dos Deputados**, votado como destaque em separado na **sessão extraordinária do dia 17.12.2014**, em razão dos requerimentos feitos pelos Senadores Eduardo Braga e Humberto Costa (cf. votação no *DSF* de 18.12.2014, p. 523).

Outro ponto nos chama a atenção: no **parecer final da Câmara dos Deputados** (PL 6.065/2005 — que produziu o denominado “substitutivo da

CD”) e que **definiu essa redação final que estamos criticando**, os Relatores (tanto o Deputado Paulo Teixeira como o Deputado Sérgio Barradas Carneiro), ao analisarem o **PL n. 2.066/2007** (que pretendia **revogar** esse dispositivo que estabelece a inexigibilidade de título fundado em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal), deixavam claro que, no tocante ao controle difuso, o efeito pretendido **dependeria de edição da resolução pelo Senado Federal**.

Assim, sustentamos que, ao se interpretar essa regra de defesa na execução introduzida pelo CPC/2015, somente se admitam esses “embargos rescisórios” se a decisão de inconstitucionalidade **anterior** pelo STF se der em controle concentrado ou, se em controle difuso, a norma tiver a sua execução suspensa pelo Senado Federal (art. 52, X).

Finalmente, a outra hipótese de defesa (**também introduzida pelo substitutivo da CD, não estando prevista no projeto original do SF**) poderá ser apresentada se a decisão que funda a execução tiver sido proferida **antes** da nova interpretação a ser dada pelo STF. Tanto o **art. 525, § 15**, como o **art. 535, § 8.º**, admitem o cabimento de **ação rescisória** cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.

Nesse ponto, remetemos o leitor para discussão que trouxemos no *item 6.7.1.17.4.2*, devendo deixar bem claro que, segundo sustentamos, referida ação rescisória (e melhorou ao não mais se falar em “embargos rescisórios”) deverá observar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da decisão individual (e que funda a execução) e somente se o reconhecimento da inconstitucionalidade **posterior** pelo STF se der em **controle concentrado** tendo em vista o seu efeito *erga omnes* e *ex tunc* — retroativo, a reconhecer a nulidade *ab origine* do ato normativo que funda a execução (**não se admitindo a hipótese de controle difuso, nem mesmo**, para essa situação, **a edição de resolução do Senado Federal** que teria efeito *ex nunc* e, portanto, não retroativo, não atingindo a decisão anterior e que está servindo de fundamento para a execução impugnada).

Para essa última questão, vamos aguardar como o STF interpretará a matéria,

lembrando que esse tema está sendo discutido nas [ADIs 2.418](#) e [3.740](#), que têm por objeto os arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73 ([matéria pendente](#) — cf. *item 6.7.1.17.4.3*).

■ **6.7.1.17.4.4. Aspectos conclusivos: efeito da decisão no plano normativo (“Normebene”) e no plano do ato singular (“Einzelaktebene”) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão (interessante tendência apontada pelo Min. Gilmar Mendes). Perspectiva introduzida pelo CPC/2015**

O efeito vinculante, seja decorrente do controle concentrado (ADI ou ADC), seja, ainda, acrescente-se, em razão da edição de súmula vinculante, seja em razão de aprovação de Resolução por parte do Senado Federal (neste caso, não se aceitando a teoria da transcendência no controle difuso — cf. *item 6.6.5*), produzirá impacto sobre as situações individuais (no caso da Resolução do SF, com efeitos, por regra, não retroativos e, então, somente em relação aos processos que não tenham transitado em julgado).

Estando em curso ação individual e sobrevindo decisão em controle concentrado ou edição de súmula vinculante, ou Resolução do SF, o juiz do processo individual, ainda não findo, ficará vinculado, devendo decidir a questão prejudicial de inconstitucionalidade nos exatos termos do estabelecido no processo coletivo. Isso decorre do [efeito vinculante](#) da decisão.

Sobrevindo decisão do processo individual em desrespeito a entendimento prévio já fixado em controle concentrado de constitucionalidade, com efeito *ex tunc*, vinculante e *erga omnes*, ou em desrespeito a súmula vinculante ou a anterior Resolução do Senado Federal, parece razoável sustentarmos a desconstituição da coisa julgada individual (posterior) por ação rescisória e desde que dentro do prazo decadencial de 2 anos, com fundamento no art. 485, IV, CPC/73 (idêntico ao art. 966, IV, do CPC/2015), por ofensa a coisa julgada anterior (do processo coletivo).

Por outro lado, modificando o STF o entendimento da tese jurídica em controle concentrado ou vindo a editar súmula vinculante, eventual sentença

individual transitada em julgado (lembrando que se estiver pendente de recurso o tribunal estaria também vinculado ao novo posicionamento) caracterizar-se-á como **sentença individual inconstitucional**. Nesse caso, só se poderia pensar em desconstituição da coisa julgada individual anterior por meio de **rescisória**, tendo por fundamento o art. 485, V, do CPC/73 (correspondente ao art. 966, V, CPC/2015) e se afastando a regra fixada na S. 343/STF somente se a controvérsia for de **natureza constitucional**, à luz do princípio da força normativa da Constituição e do STF na condição de seu intérprete final.

Para esta hipótese, contudo, a rescisória deve, necessariamente, respeitar o prazo decadencial de 2 anos, que deverá ser contado do trânsito em julgado da sentença individual, e não a partir da nova posição do STF, sob pena de se caracterizar uma indesejável perpetuação da **“Espada de Dâmocles”** e violação aos princípios constitucionais da **segurança jurídica** e da **autoridade das decisões do Poder Judiciário** (o tema precisa ser analisado pelo STF à luz do CPC/2015, conforme destacado nos itens anteriores — pendente).

Em outro sentido, havendo *ato singular individual* anterior, além do prazo decadencial de 2 anos, com a ressalva da matéria penal (**revisão criminal**), a coisa julgada individual deverá ser respeitada e o sistema terá de conviver com as sentenças contraditórias.

Ilustramos com interessante voto do Min. Gilmar Mendes:

“EMENTA: Além disso, acentue-se, desde logo, que, no direito brasileiro, jamais se aceitou a ideia de que a nulidade da lei importaria na eventual nulidade de todos os atos que com base nela viessem a ser praticados. Embora a ordem jurídica brasileira não disponha de preceitos semelhantes aos constantes do § 79 da Lei do *Bundesverfassungsgericht*, que prescreve a **intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação, não se deve supor que a declaração de nulidade afete, entre nós, todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional**. É verdade que o nosso ordenamento não contém regra expressa sobre o assunto, aceitando-se, genericamente, a ideia de que o ato fundado em lei inconstitucional está eivado, igualmente, de iliceidade (cf., a propósito, RMS 17.976, Rel. Amaral Santos, *RTJ* 55, p. 744). Concede-se, porém, proteção ao ato singular, em

homenagem ao **princípio da segurança jurídica**, procedendo-se à diferenciação entre o **efeito da decisão no plano normativo (*Normebene*) e no plano do ato singular (*Einzelaktebene*) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão** (cf. Ipsen, Jörn, *Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt*, Baden-Baden, 1980, p. 266 e s. Ver, também, Mendes, Gilmar, *Jurisdição constitucional*, 5.^a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 334)” (RE 217.141-AgR, voto do Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2006, DJ de 04.08.2006).

Fora dessa hipótese, a desconstituição da coisa julgada só poderá ter por fundamento a **colisão com outros valores constitucionais**, situação essa verificada à luz dos princípios da **razoabilidade** e da **proporcionalidade** e se o magistrado entender que o princípio da segurança jurídica deva ser afastado, e em situações excepcionalíssimas.

CUIDADO: em decisão extremamente relevante, o STF aplicou a técnica da ponderação mesmo depois de findo o prazo da ação rescisória.

Tratava-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TJDF que acolheu preliminar de coisa julgada e determinou a **extinção** de **nova** ação de investigação de paternidade proposta em razão da agora viabilidade de realização do exame de DNA, tendo em vista que a questão já estava decidida havia **mais de 10 anos!**

À época, o recorrente, representado por sua genitora, ingressou com ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, que foi julgada improcedente, **por insuficiência de provas**. Sustentaram que o recorrente, no primeiro julgamento, não tinha condições financeiras de custear o exame de DNA. Com a promulgação da Lei Distrital n. 1.097/96, o Poder Público passou a custear o referido exame.

No caso concreto, em **situação excepcionalíssima**, o STF afastou a alegação de segurança jurídica para fazer valer o *direito fundamental que toda pessoa tem de conhecer as suas origens* (**princípio da busca da identidade genética**), especialmente se, à época da decisão que se procura rescindir, não se pôde fazer o exame de DNA.

A decisão foi tomada, em **02.06.2011**, por **7 x 2**, no julgamento do **RE 363.889**, concedendo ao recorrente o direito de voltar a pleitear, perante o suposto pai, a realização do **exame de DNA**, tendo em vista que, na primeira decisão, embora beneficiária da assistência judiciária, a recorrente não podia arcar com as custas para a sua realização:

“EMENTA: (...). 1. É dotada de **repercussão geral** a matéria atinente à possibilidade da propositura de **ação de investigação de paternidade**, quando anterior demanda **idêntica**, entre as **mesmas partes**, foi julgada improcedente, por **falta de provas**, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o **exame de DNA** e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. **Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo**. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da **identidade genética**, como natural **emanação do direito de personalidade** de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o **direito à igualdade entre os filhos**, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da **paternidade responsável**” (**RE 363.889**, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.06.2011, *DJE* de 16.12.2011).

Sobre esse tema, devemos destacar uma **novidade introduzida pelo CPC/2015**.

De acordo com o **art. 966, VII**, como nova previsão explícita de cabimento de ação rescisória, a decisão de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, **prova nova** cuja **existência ignorava** ou de que **não pôde fazer uso**, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Nesse caso, contudo, conforme art. 975, § 2.º, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da **prova nova**, observado o prazo máximo de **5 anos**, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

■ 6.7.1.17.5. Pedido de cautelar (ADI genérica)

O art. 102, I, “p”, da CF/88 estabelece que cabe ao STF processar e julgar, originariamente, o pedido de cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade.

De acordo com o *caput* do art. 10 da Lei n. 9.868/99, salvo no período de recesso,²⁰⁷ a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da **maioria absoluta (6 Ministros)** dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22 (**quorum de instalação da sessão de julgamento** com pelo menos **8 Ministros** dos 11), após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias, dispensada essa audiência em caso de **excepcional urgência**, hipótese em que o Tribunal poderá deferir a medida cautelar (art. 10, § 3.º).

Julgando indispensável, o relator ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 dias, sendo facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma do Regimento do Tribunal (art. 10, §§ 1.º e 2.º).

Desde que presentes os requisitos do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris*, poderá ser concedida a liminar, suspendendo a eficácia do ato normativo.

E quais seriam os efeitos da concessão da medida cautelar? De acordo com os §§ 1.º e 2.º do art. 11 da Lei n. 9.868/99, em total consonância com o posicionamento do STF, a concessão da medida cautelar terá eficácia contra todos (***erga omnes***) e efeito ***ex nunc***, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa (***ex tunc***). No julgamento de questão de ordem em agravo regimental interposto na **Rcl 1.880**, o STF, por maioria, reservou-se para examinar, quando necessário para o julgamento da causa, a questão sobre a extensão do **efeito vinculante** às medidas liminares em ação direta de inconstitucionalidade (cf. **Inf. 289/STF**, de 04 a 08.11.2002). A **concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário**.

Ainda, de acordo com o art. 12 da Lei, havendo pedido de medida cautelar, o

relator, em face da **relevância da matéria** e de seu **especial significado para a ordem social e a segurança jurídica**, poderá, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, **submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação**.

E quais seriam os efeitos do indeferimento da medida cautelar? O STF, revendo posição anterior, definiu que o indeferimento da cautelar **não** significa a confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante.

Portanto, na medida em que não se poderá sustentar o efeito vinculante da decisão de indeferimento, conforme anotou o STF, “não se admite reclamação contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, indefere, sob qualquer que seja o fundamento, pedido de liminar” (Rcl 3.458-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.10.2007, *DJE* de 23.11.2007). Nesse sentido, se algum juiz em sede de controle difuso afastar a aplicação da lei, declarando-a inconstitucional de modo incidental, contra essa decisão não caberá reclamação.

■ **6.7.1.18. Reclamação para a garantia da autoridade da decisão do STF: paradigma de ordem objetiva (ADI genérica e súmula vinculante)**

■ **6.7.1.18.1. Regras gerais**

A fim de garantir a **autoridade da decisão proferida pelo STF**, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a Excelsa Corte reconhece o ajuizamento de **reclamação**, nos termos do art. 102, I, “I” (competência originária do STF), desde que o ato judicial que se alega tenha desrespeitado sua decisão **não** tenha transitado em julgado (**S. 734/STF, 26.11.2003**).

Ainda, a partir da EC n. 45/2004 (*Reforma do Poder Judiciário*), admite-se o instituto da reclamação para resguardar a correta aplicação das **súmulas vinculantes** (art. 103-A, § 3.º, CF/88).

Dessa forma, conforme entende o STF, “para que seja admitido o seu

manejo, a decisão da Suprema Corte, cuja autoridade venha a estar comprometida, deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia *erga omnes*”, não se admitindo paradigma de ordem subjetiva (Min. Dias Toffoli, Rcl 14.810-AgR, j. 23.05.2013). [208](#)

Conforme sustentamos, a previsão de efeito vinculante a abrir o caminho diretamente ao STF tem que estar **explícita na Constituição Federal**, seja em sua redação originária (decisões em controle concentrado), seja em razão de emenda à Constituição (súmulas vinculantes), não podendo haver ampliação por lei infraconstitucional.

Por isso, algumas novidades introduzidas pelo **CPC/2015** são **inconstitucionais**. Conforme dissemos, muito embora se reconheça a eficácia expansiva das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias concretas e individuais, há que se dar uma **interpretação estrita para o cabimento da reclamação constitucional**, sob pena de transformar o STF em Corte de revisão, em órgão recursal, tendo em vista a criação de um inadmissível (porque **inconstitucional**) atalho processual ou, ainda, um acesso *per saltum* à Suprema Corte em combatida supressão de instância (cf. *item 6.6.5.2*).

E quais os **legitimados** para a sua propositura?

Até o julgamento de questão de ordem na Reclamação n. 1.880, em 07.11.2002, a jurisprudência do STF, mesmo após o advento da Lei n. 9.868/99, **em um primeiro momento**, não considerava parte interessada para a propositura da referida ação terceiros que tivessem, subjetivamente, interesse jurídico ou econômico na observância da decisão, já que o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, como justificavam, fazia instaurar um processo objetivo, sem partes, no qual inexistia litígio referente a situações concretas ou individuais. Assim, nessa primeira fase, só seria conhecida a reclamação se proposta por um dos legitimados do art. 103 da CF/88 (art. 2.º da Lei n. 9.868/99) e com idêntico objeto, mesmo que o referido autor não tivesse sido parte na ação direta de inconstitucionalidade cuja decisão fundava o pedido reclamatório (legitimação concorrente — cf. Rcl 354, Rel. Min. Celso de Mello). [209](#)

Declarando **novo posicionamento (07.11.2002)**, coincidente com o por nós exposto nas edições anteriores deste trabalho, o STF, por maioria de votos, após o julgamento de questão de ordem em agravo regimental, declarou **constitucional o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99**, passando a considerar parte legítima para a propositura de reclamação **todos aqueles que forem atingidos por decisões contrárias ao entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento de mérito proferido em ação direta de inconstitucionalidade**, havendo, assim, uma **ampliação do conceito de parte interessada** (art. 13 da Lei n. 8.038/90). [210](#)

Esse novo entendimento é reforçado com a redação conferida ao art. 102, § 2.º, da CF/88 pela EC n. 45/2004 (*Reforma do Poder Judiciário*), no seguinte sentido: “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e **efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Para se ter um exemplo da amplitude da perspectiva do instituto da reclamação, havendo efeito vinculante até mesmo perante a Administração Pública, temos sustentado a possibilidade de ajuizamento de reclamação em face de ato de Prefeito que contraria decisão proferida pelo STF com caráter vinculante.

Do ponto de vista do procedimento, conforme anotou o STF, “... para o conhecimento da reclamação não se exige a juntada de cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal que teria sido desrespeitado. Dispensabilidade da peça em virtude do acórdão ter sido proferido pela própria Suprema Corte” (Rcl 6.167-AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes Direito, j. 18.09.2008, *DJE* de 14.11.2008).

Finalmente, em interessante decisão, o STF admitiu, no julgamento de reclamação, a mudança na interpretação dada a determinado ato normativo (e que serviu de paradigma), declarando, inclusive, a sua inconstitucionalidade incidental. [211](#)

■ 6.7.1.18.2. *Natureza jurídica do instituto da reclamação*

A **natureza jurídica** da reclamação foi bem desenvolvida pelo Ministro Marco Aurélio, e pedimos vênia para transcrevê-la abaixo de maneira esquematizada e acrescentando outras perspectivas:[212](#)

■ **ação** — Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, Forense, t. V, p. 384;

■ **recurso ou sucedâneo recursal** — Moacyr Amaral Santos, *RTJ* 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, *O Poder Judiciário e a nova Constituição*, Aide, 1989, p. 80;

■ **remédio incomum** — Orozimbo Nonato, apud Cordeiro de Mello, *O processo no Supremo Tribunal Federal*, v. 1, p. 280;

■ **incidente processual** — Moniz de Aragão, *A correição parcial*, 1969, p. 110;

■ **medida de direito processual constitucional** — José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, 9. ed., Saraiva, 1987, v. 3, 2.^a parte, p. 199, item n. 653;

■ **medida processual de caráter excepcional** — Ministro Djaci Falcão, *RTJ* 112/518-522;

■ **instrumento de extração constitucional** — “inobstante a origem pretoriana de sua criação (*RTJ* 112/504), destinada a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘I’) e do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, ‘f’)” — Ementa da Rcl 336, Rel. Min. Marco Aurélio;

■ **simples postulação perante o próprio órgão que proferiu uma decisão para o seu exato e integral cumprimento** — Grinover (Da reclamação, *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 38/80);

provimento mandamental de natureza constitucional — Pedro Lenza, para este trabalho.

É de realçar o pensamento de Grinover ao analisar a natureza jurídica do **instituto da reclamação**: “... não se trata de ação, uma vez que não se vai rediscutir a causa com um terceiro; não se trata de recurso, pois a relação processual já está encerrada, nem se pretende reformar a decisão, mas antes garanti-la; não se trata de incidente processual, porquanto o processo já se encerrou. Cuida-se simplesmente de postular perante o próprio órgão que proferiu uma decisão o seu exato e integral cumprimento”. [213](#)

Já sustentamos, em outro estudo, [214](#) a conclusão trazida por Grinover, qual seja, tratar-se a **reclamação** de verdadeiro **exercício constitucional de direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder** (CF, art. 5.º, XXXIV, “a”). [215](#)

Esse entendimento parece agora estar consagrado no STF, o que se observa pela ementa da **ADI 2.480**, j. 02.04.2007, *DJ* de 15.06.2006, na qual se aceitou a previsão da reclamação também para o controle de constitucionalidade estadual e com previsão na CE. [216](#)

Poderíamos dizer, então, que a **reclamação** nada mais é que um **instrumento de caráter mandamental e natureza constitucional**.

■ 6.7.2. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

■ 6.7.2.1. Conceito (ADC)

A **ação declaratória de constitucionalidade** foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993 (*DOU* de 18.03.1993), com a alteração da redação do art. 102, I, “a”, e acréscimo do § 2.º ao art. 102, bem como do § 4.º ao art. 103, tendo sido regulamentado o seu processo e julgamento pela Lei n. 9.868/99.

Busca-se por meio dessa ação declarar a **constitucionalidade de lei ou ato normativo federal**. Indaga-se: mas toda lei não se presume constitucional? Sim, no entanto, o que existe é uma presunção relativa (*juris tantum*) de toda lei ser

constitucional. Em se tratando de presunção relativa, admite-se prova em contrário, declarando-se, quando necessário, através dos mecanismos da ADI genérica ou do controle difuso, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.

Pois bem, qual seria, então, a utilidade dessa ação? O objetivo da ADC é transformar uma presunção **relativa** de constitucionalidade em **absoluta** (*jure et de jure*), não mais se admitindo prova em contrário. Ou seja, julgada procedente a ADC, tal decisão vinculará os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública, que não mais poderão declarar a inconstitucionalidade da aludida lei, ou agir em desconformidade com a decisão do STF. Não estaremos mais, repita-se, diante de uma presunção relativa de constitucionalidade da lei, mas **absoluta**.

Deve-se deixar claro que ao se falar em “presunção absoluta” no modelo do **processo objetivo** não significa a impossibilidade eterna de rever o entendimento. Como sabemos, o STF poderá mudar de posição, alterando a interpretação dada ao ato normativo federal e, no caso, sem dúvida, declarar, em decisão futura, a sua inconstitucionalidade. Em outras palavras, o efeito vinculante não “vincula” o STF (Pleno) que poderá alterar o seu posicionamento. Mas, naturalmente, enquanto não observada essa “viragem jurisprudencial” pela mais alta Corte do país, os juízes e tribunais, em razão do efeito vinculante da decisão, deverão a ela se curvar.

Em síntese, a ADC busca afastar o nefasto quadro de insegurança jurídica ou incerteza sobre a validade ou aplicação de lei ou ato normativo federal, preservando a ordem jurídica constitucional.

■ 6.7.2.2. Objeto (ADC)

O objeto da referida ação é **lei ou ato normativo federal**. Frise-se: somente lei ou ato normativo federal, diferentemente do que ocorre com a ADI genérica, cujo objeto engloba, também, a lei ou ato normativo estadual (cf. art. 102, § 2.º).

■ 6.7.2.3. Competência (ADC)

O órgão competente para apreciar a ADC é o **STF**, conforme estabelece o art. 102, I, “a”, da CF/88, de forma originária.

■ 6.7.2.4. *Legitimidade (ADC)*

Antes da **EC n. 45/2004**, os legitimados para a propositura da referida ação eram apenas quatro, de acordo com o art. 103, § 4.º, da CF/88, quais sejam: *a)* Presidente da República; *b)* Mesa do Senado Federal; *c)* Mesa da Câmara dos Deputados; *d)* Procurador-Geral da República.

Com a revogação do § 4.º e a nova redação do *caput* do art. 103, pela aludida emenda, os legitimados para a propositura da ADC passaram a ser os **mesmos da ADI genérica** (*vide item 6.7.1.14*).

■ 6.7.2.5. *Procedimento (ADC)*

O procedimento na ADC é praticamente o mesmo seguido na ADI genérica, mas algumas observações devem ser feitas.

Em um primeiro momento, entendeu a doutrina não ser justificável a citação do Advogado-Geral da União na medida em que inexistia ato ou texto impugnado, já que se afirma a constitucionalidade na inicial.

Nesse ponto, contudo, gostaríamos de abrir uma discussão: em sendo ADI e ADC ações dúplices ou ambivalentes, ações com sinais trocados, em caso de improcedência do pedido na ADC, os efeitos, se assim decidido pelo STF, serão os mesmos da hipótese de deferimento da ADI, qual seja, a **inconstitucionalidade da lei**. Por esse motivo, parece razoável afirmar que o AGU tenha de ser sempre citado na ADC para não se desrespeitar o art. 103, § 3.º (**matéria pendente**). Vejamos graficamente, a perspectiva dessa ambivalência:

ADI e ADC são ações dúplices ou ambivalentes, ou seja, são “ações com sinais

troçados".		
A procedência de uma implica a improcedência da outra		
Ação	■ ADI (ação direta de inconstitucionalidade)	■ ADC (ação declaratória de constitucionalidade)
Resultado do julgamento	■ (+) procedência	■ (-) improcedência
Consequência em relação à lei	■ inconstitucionalidade	■ inconstitucionalidade

O Procurador-Geral da República, por força do art. 103, § 1.º, da CF/88, deverá ser previamente ouvido, emitindo o seu parecer.

Um requisito intrínseco à inicial, conforme vem relatando o STF, necessário para o conhecimento e análise do mérito, seria a demonstração da “*controvérsia judicial que põe risco à presunção de constitucionalidade do ato normativo sob exame... permitindo à Corte o conhecimento das alegações em favor da constitucionalidade e contra ela, e do modo como estão sendo decididas num ou noutro sentido*”.²¹⁷

Outro requisito, também exposto pelo Ministro relator Moreira Alves na ADC citada, seria, quando alegado **vício formal de inconstitucionalidade**, a necessária juntada aos autos de cópia dos documentos relativos ao processo legislativo de formação da lei ou ato normativo federal.

Esses dois requisitos que o STF vinha exigindo jurisprudencialmente foram expressamente previstos na Lei n. 9.868/99, que, em seu art. 14, estabelece que a petição inicial indicará: *a)* o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido; *b)* o pedido, com suas especificações; *c)* a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Determina também a referida lei que a petição inicial deverá conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de

constitucionalidade.

A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão **liminarmente indeferidas** pelo relator, cabendo **agravo** dessa decisão (art. 15 da lei).

De acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Após a indispensável manifestação do PGR, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

Convém notar, seguindo a linha procedimental adotada na ADI, que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Pode, ainda, o relator solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição.

De acordo com a lei, as informações, perícias e audiências serão realizadas no prazo de **30 dias**, contado da solicitação do relator.

As regras sobre votação e *quorum* são as mesmas expostas na ADI genérica: desde que presente o *quorum* para instalação da sessão de julgamento de **8 Ministros**, a declaração de constitucionalidade dar-se-á pelo *quorum* da **maioria absoluta dos 11 Ministros do STF, isto é, pelo menos 6 deverão posicionar-se favoráveis à procedência da ação**.

Por fim, é **vedada a intervenção de terceiros** (muito embora, conforme

visto no *item 6.7.1.16.2*, cabível *amicus curiae*) e a **desistência** da ação após a sua propositura. A decisão é **irrecorrível**, ressalvada a interposição de **embargos declaratórios, não podendo ser objeto de ação rescisória**.

■ 6.7.2.6. *Efeitos da decisão (ADC)*

O art. 102, § 2.º, criado pela EC n. 3/93, estabelece que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo **STF**, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo **federal**, produzirão **eficácia contra todos** e **efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Assim, podemos sistematizar os efeitos como sendo:

erga omnes (eficácia contra todos);

ex tunc;

■ **vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital.**

■ 6.7.2.7. *Medida cautelar (ADC)*

Inovação trazida pelo Projeto de lei n. 2.960/97 (PL n. 10/99, no Senado Federal), que originou a lei n. 9.868/99, tão comentada nesta parte do trabalho, foi a admissão de medida cautelar nas ações declaratórias de constitucionalidade.

Nesse sentido, o art. 21 prevê que o STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais **suspendam** o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.

Essa suspensão perdurará apenas por 180 dias contados da publicação da parte dispositiva da decisão no *DOU*, prazo esse definido pela lei para que o tribunal julgue a ação declaratória. Findo tal prazo, sem julgamento, cessará a eficácia da medida cautelar.

Malgrado posicionamento minoritário em contrário, [218](#) o STF, por votação

majoritária, apreciando preliminar suscitada pelo Ministro *Sydney Sanches*, quanto ao cabimento ou não de liminar em ação declaratória, no julgamento da **ADC (MC) 4**, pacificou o entendimento segundo o qual é perfeitamente possível a atribuição de **efeito vinculante** e *erga omnes* em sede de liminar (decisão não definitiva de mérito) na ADC, tendo em vista o **poder geral de cautela** da Corte, podendo suas decisões ser preservadas pelo instrumento da **reclamação** (CF, art. 102, I, “I”). [219](#)

Finalmente, na hipótese de indeferimento de cautelar, em razão do efeito ambivalente da ação, referida decisão significaria o mesmo que a procedência da ADI (ações dúplices ou ambivalentes). Assim, se no dispositivo da decisão se manifestar a Corte, respeitando os requisitos legais, parece-nos que se poderia estabelecer o efeito vinculante e *erga omnes* em relação a essa decisão que equivaleria à concessão da cautelar em ADI.

■ 6.7.3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)

■ 6.7.3.1. Localização (ADPF)

O § 1.º do art. 102 da CF/88, de acordo com a EC n. 3/93, estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da CF/88, será apreciada pelo STF, na forma da lei.

A **Lei n. 9.882/99**, regulamentando o dispositivo constitucional, definiu as regras procedimentais para a aludida arguição.

Cabe salientar que, antes do advento da Lei n. 9.882/99, o STF decidiu que o art. 102, § 1.º, da CF/88 materializava norma constitucional de **eficácia limitada**, ou seja, enquanto não houvesse lei descrevendo a forma da nova ação constitucional, a Suprema Corte não poderia apreciá-la. [220](#)

■ 6.7.3.2. Objeto — hipóteses de cabimento (ADPF)

A arguição de descumprimento de preceito fundamental será cabível, nos termos da lei em comento, seja na modalidade de **arguição autônoma** (direta), seja na hipótese de **arguição incidental**.

O art. 1.º, *caput*, da Lei n. 9.882/99 disciplinou a hipótese de **arguição autônoma**, tendo por objeto *evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público*.

Percebe-se nítido caráter **preventivo** na primeira situação (**evitar**) e caráter **repressivo** na segunda (**reparar lesão a preceito fundamental**), devendo haver **nexo de causalidade** entre a **lesão ao preceito fundamental** e o **ato do Poder Público**, de que esfera for, não se restringindo a atos normativos, podendo a lesão resultar de **qualquer ato administrativo**, inclusive **decretos regulamentares**.

A segunda hipótese (**arguição incidental**), prevista no parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99, prevê a possibilidade de arguição quando for **relevante** o *fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal (e por consequência o distrital, acrescente-se), incluídos os anteriores à Constituição*.

Nessa hipótese, deverá ser demonstrada a **divergência jurisdicional (comprovação da controvérsia judicial) relevante** na aplicação do ato normativo, violador do preceito fundamental.

Observa-se, então, que essa segunda modalidade de **arguição (incidental)**, além de se restringir a **ato normativo**, pressupõe a demonstração de controvérsia judicial relevante, o que faz crer a existência de uma **demanda concreta**, tanto é que o art. 6.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99 autoriza ao relator, se entender necessário, **ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição**.

Busca-se, nesse sentido, procedendo a uma cisão funcional em relação ao caso concreto, antecipar o entendimento da Suprema Corte sobre a matéria.

Gilmar Mendes, nesse caso, fazendo um contraponto ao art. 97 em relação ao qual se observa uma *cisão funcional horizontal*, no caso da ADPF incidental, vislumbra uma **cisão funcional no plano vertical (de órgãos das instâncias**

ordinárias para o STF). [221](#)

Ainda, cabe notar, na medida em que a ADPF pode ter por objeto ato editado antes da Constituição, a sua importante utilização como **instrumento de análise em abstrato de recepção** de lei ou ato normativo.

Nessa hipótese, conforme anotou o Min. Gilmar Mendes, a revogação da lei ou do ato normativo editado antes do novo ordenamento jurídico e objeto da demanda “não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não recepção da norma pela ordem constitucional superveniente” (**ADPF 33**, j. 07.12.2005, Plenário).

Convém advertir que no julgamento da **ADI 2.231-MC/DF**, proposta pelo Conselho Federal da OAB, “... o Min. Néri da Silveira, relator, em face da generalidade da formulação do parágrafo único do art. 1.º, considerou que esse dispositivo autorizaria, além da arguição autônoma de caráter abstrato, a **arguição incidental em processos em curso**, a qual **não poderia ser criada pelo legislador ordinário**, mas, tão só, por via de **emenda constitucional**, e, portanto, proferiu voto no sentido de dar ao texto **interpretação conforme** à CF a fim de excluir de sua aplicação **controvérsias constitucionais concretamente já postas em juízo**” (*Inf. 253/STF*) (**matéria pendente**).

Apesar de não julgada referida ADI, parece, em razão de alguns precedentes do STF, que essa tese não deve prosperar.

■ 6.7.3.3. *Preceito fundamental — conceito (ADPF)*

Tanto a Constituição como a lei infraconstitucional deixaram de conceituar **preceito fundamental**, cabendo essa tarefa à doutrina e, em última instância, ao STF.

Até o momento, os Ministros do STF não definiram, com precisão, o que entendem por preceito fundamental. Em algumas hipóteses, disseram **o que não é preceito fundamental**. Para se ter um exemplo, na apreciação da questão de ordem da ADPF 1-RJ, apresentada pelo Ministro relator Néri da Silveira, o Tribunal não conheceu de arguição de descumprimento de preceito fundamental

(CF, art. 102, § 1.º) ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil — PC do B, contra ato do Prefeito do Município do Rio de Janeiro que, ao vetar parcialmente, de forma imotivada, projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal — que elevava o valor do IPTU para o exercício financeiro de 2000 —, teria violado o princípio constitucional da separação de Poderes (CF, art. 2.º). Considerou-se ser incabível na espécie a arguição de descumprimento de preceito fundamental, dado que **o veto constitui ato político do Poder Executivo, insuscetível de ser enquadrado no conceito de ato do Poder Público**, previsto no art. 1.º da Lei n. 9.882/99 (“A arguição prevista no § 1.º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”) (*Inf. 176/STF*).

Valemo-nos, então, de algumas sugestões da doutrina.

Para o Professor Cássio Juvenal Faria, preceitos fundamentais seriam aquelas “normas qualificadas, que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais, por exemplo, os ‘princípios fundamentais’ do Título I (arts. 1.º ao 4.º); os integrantes da cláusula pétrea (art. 60, § 4.º); os chamados princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII); os que integram a enunciação dos direitos e garantias fundamentais (Título II); os princípios gerais da atividade econômica (art. 170); etc.”. [222](#)

Para Bulos, “qualificam-se de *fundamentais* os grandes preceitos que informam o sistema constitucional, que estabelecem comandos basilares e imprescindíveis à defesa dos pilares da manifestação constituinte originária”. Como exemplos o autor lembra os arts. 1.º, 2.º, 5.º, II, 37, 207 etc. [223](#)

■ 6.7.3.4. Competência (ADPF)

De acordo com o art. 102, § 1.º, da CF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental será apreciada pelo **STF** (competência originária), na forma da lei.

■ 6.7.3.5. *Legitimidade (ADPF)*

Os legitimados para a propositura da referida ação são os **mesmos da ADI genérica**, previstos no art. 103, I a IX, da CF/88 e no art. 2.º, I a IX, da Lei n. 9.868/99 (cf. o art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99), com as observações sobre a **pertinência temática** expostas quando do comentário sobre a ADI genérica.

O art. 2.º, II, da Lei n. 9.882/99 permitia a legitimação para **qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público**, mas foi **vetado**.

Apesar do **veto**, o art. 2.º, § 1.º, estabelece que, “na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao **Procurador-Geral da República**, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo”.[224](#)

■ 6.7.3.6. *Procedimento (ADPF). Particularidades do princípio da subsidiariedade*

Proposta a ação diretamente no **STF**, por um dos legitimados, deverá o relator sorteado analisar a regularidade formal da petição inicial, que deverá conter, além dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) e observância das regras regimentais: **a)** a indicação do preceito fundamental que se considera violado; **b)** a indicação do ato questionado; **c)** a prova da violação do preceito fundamental; **d)** o pedido, com suas especificações; **e)** se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação (parágrafo único do art. 3.º da lei em análise).

Liminarmente, o relator, não sendo o caso de arguição, faltante um dos requisitos apontados, ou inepta a inicial, indeferirá a petição inicial, sendo cabível

o **recurso de agravo**, no prazo de **5 dias**, para atacar tal decisão (art. 4.º § 2.º, da Lei n. 9.882/99).

De acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Fundamental notar que, consoante o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio **eficaz** capaz de sanar a lesividade. Trata-se do **princípio da subsidiariedade** (caráter residual), que, segundo o Ministro Celso de Mello, condiciona o ajuizamento da ação à “... ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a lesividade indicada pelo autor” (ADPF-6/RJ, *DJ* de 19.09.2000. *Vide*, ainda, ADPF 3, questão de ordem, *DJ* de 26.03.2001). Trata-se, conforme anotou em outro julgado, de “**pressuposto negativo de admissibilidade**”, atuando a “cláusula da subsidiariedade” como “**causa obstativa**” para o ajuizamento da ADPF no STF (**ADPF 314 AgR/DF**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2014, Plenário, *DJE* de 19.02.2015).

Evoluindo, o STF entendeu que o **princípio da subsidiariedade** deve ser interpretado no contexto da **ordem constitucional global** e em relação aos processos de índole objetiva (ADI, ADC, ADO): “(...) inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, *a priori*, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação” (**ADPF 33**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.12.2005, *DJ* de 27.10.2006. No mesmo sentido: ADPF 47-MC, Rel. Min. Eros Grau, j.

07.12.2005, *DJ* de 27.10.2006).

Havendo pedido de liminar e apreciado pelo relator, este solicitará as informações necessárias às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de 10 dias, podendo, ainda, caso entenda necessário, ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição (no caso, a **arguição incidental**), requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou, ainda, fixar data para declarações, em **audiência pública** (cf. **ADPF 101** — *importação de pneus usados* — 27.06.2008 e **ADPF 54** — *interrupção de gravidez por anencefalia* — 26 e 28 de agosto e 4 e 16 de setembro, todas em 2008), de pessoas com experiência e autoridade na matéria (art. 6.º e § 1.º, da Lei n. 9.882/99).

Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo.

Assim, conforme visto no *item 6.7.1.16.3*, o STF, **excepcionalmente**, vem admitindo *amicus curiae* na ADPF, aplicando, por analogia, o art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99, desde que se demonstrem a **relevância da matéria** e a **representatividade dos postulantes** (cf. **ADPFs 33, 46, 73, 132, 183, 205** etc.).

Ouvido o MP (art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99, acatando o mandamento do art. 103, § 1.º, da CF/88), o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, pedindo dia para julgamento.

Da mesma forma que ocorre no julgamento da ADI, a decisão (julgamento) sobre a arguição será proferida pelo *quorum* da **maioria absoluta** (art. 97 da CF/88), desde que presente o *quorum de instalação da sessão de julgamento*, previsto no art. 8.º da Lei n. 9.882/99, ou seja, a exigência de estarem presentes pelo menos **2/3 dos Ministros (8 dos 11 Ministros)**.

Tal como se verifica no processo de ADI, a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental é **irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória** (art. 12 da Lei n. 9.882/99).

Apesar do silêncio da lei, bem como da afirmação da irrecorribilidade,

entendemos perfeitamente cabíveis os **embargos de declaração**, em razão de sua natureza jurídica de integração e esclarecimento da decisão e, também, com fundamento no art. 26 da Lei n. 9.868/99 (ADI e ADC), aplicado por analogia. [225](#)

Finalmente, a lei é explícita ao assegurar o cabimento de **reclamação** contra o descumprimento da decisão proferida pelo STF, na forma do seu Regimento Interno (art. 13 da Lei n. 9.882/99).

■ 6.7.3.7. *Efeitos da decisão (ADPF)*

Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

A decisão é **imediatamente autoaplicável**, na medida em que o presidente do STF determinará o **imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente**.

De acordo com o art. 10, § 2.º, da Lei n. 9.882/99, dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do *Diário da Justiça* e do *Diário Oficial da União*.

A decisão terá eficácia contra todos (*erga omnes*) e **efeito vinculante** relativamente aos demais órgãos do Poder Público, além de efeitos retroativos (*ex tunc*).

Da mesma maneira como acontece na ADI, como exceção à regra geral do princípio da nulidade, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada de **2/3** de seus membros, **restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado (*ex nunc*) ou de outro momento que venha a ser fixado**.

■ **6.7.3.8. O parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99 é inconstitucional (arguição incidental)?**

A constituição somente autorizou a apreciação, pelo STF, da **arguição de preceito fundamental**, na forma da **lei**.

Já havia previsto competência ao STF, em sede de ADI, para apreciação de lei ou ato normativo federal ou estadual, como já visto, **excluídos** os municipais e anteriores à Constituição.

A matéria está para ser decidida pelo STF na **ADI 2.231 (matéria pendente)**.

Para Gilmar Ferreira Mendes, surge instrumento adequado ao combate da chamada “guerra de liminares”, introduzindo profundas alterações no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade:

“Em **primeiro lugar**, porque permite a antecipação de decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes, evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da ‘interpretação autêntica’ do Supremo Tribunal Federal”.

“Em **segundo lugar**, porque poderá ser utilizado para — de forma definitiva e com eficácia geral — solver controvérsia relevante sobre a legitimidade do **direito ordinário pré-constitucional** em face da nova Constituição que, até o momento, somente poderia ser veiculada mediante a utilização do **recurso extraordinário**.”

“Em **terceiro**, porque as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses processos, haja vista a eficácia *erga omnes* e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas diversas entidades **municipais**. A solução oferecida pela nova lei é superior a uma outra alternativa oferecida, que consistiria no reconhecimento da competência dos Tribunais de Justiça para apreciar, em ação direta de inconstitucionalidade, a legitimidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Além de ensejar múltiplas e variadas interpretações, essa solução acabaria por agravar a crise do Supremo Tribunal Federal, com a multiplicação de recursos extraordinários interpostos contra as decisões proferidas pelas

diferentes Cortes estaduais” (Gilmar Ferreira Mendes, *Revista Jurídica Virtual*, n. 7, dez./1999).

■ 6.7.3.9. *Pedido de medida liminar (ADPF)*

O art. 5.º da Lei n. 9.882/99 estabelece que o STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros (pelo menos **6 Ministros**), poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Em caso de **extrema urgência ou perigo de lesão grave**, ou, ainda, em **período de recesso**, contudo, poderá o **relator** conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno.

O relator poderá, ainda, ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 dias.

A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, **salvo se decorrentes da coisa julgada**. Convém alertar que, em 05.12.2001, o Ministro Néri da Silveira (**ADI 2.231-MC/DF**) votou pelo deferimento de liminar suspendendo a eficácia deste § 3.º do art. 5.º da Lei n. 9.882/99, por estar relacionado à **arguição incidental** em processos em concreto, **vedada** sua instituição por lei, como visto.

Cabe alertar, todavia, que o Ministro Sepúlveda Pertence, relator da ADPF 77, deferiu liminar para suspender todos os processos que tramitam e estão questionando a constitucionalidade do art. 38 da Lei n. 8.880/94, que instituiu o Plano Real, até o julgamento de mérito da referida ação. E, nos termos do seu voto: “esse o quadro, defiro, em termos, *ad referendum* (por ratificação) do Plenário, o pedido de cautelar — conforme o artigo 5.º, parágrafo 3.º, da Lei 9.882/99 (ADPF) e o artigo 21 da Lei 9.868/99 — para determinar a suspensão dos processos em curso nos quais se questione a constitucionalidade ou não do artigo 38 da Lei 8.880/94”.

Devemos lembrar que o Plenário do STF conheceu da citada ADPF 77 e referendou a medida cautelar deferida (j. 19.11.2014). [226](#)

Em igual sentido, admitindo a aplicação do art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99: “Liminar concedida. Suspensão de processos e efeitos de sentenças. Servidor público. Professores do Estado de Pernambuco. Elevação de vencimentos com base no princípio da isonomia. Casos recobertos por coisa julgada material ou convalidados por lei superveniente. Exclusão da eficácia da liminar. Agravo provido em parte e referendo parcial, para esse fim. **Aplicação do art. 5.º, § 3.º, *in fine*, da Lei federal n. 9.882/99.** Não podem ser alcançados pela eficácia suspensiva de liminar concedida em ação de descumprimento de preceito fundamental os efeitos de sentenças transitadas em julgado ou convalidados por lei superveniente” (ADPF 79-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 18.06.2007, *DJ* de 17.08.2007).

Portanto, o STF vem aplicando em sua integralidade o art. 5.º, § 3.º, estando, assim, superado o posicionamento do Min. Néri da Silveira no tocante à medida liminar.

■ **6.7.3.10. ADPF pode ser conhecida como ADI? Se sim, o princípio da fungibilidade teria natureza ambivalente? Ou seja, ADI poderia ser conhecida como ADPF?**

SIM, mas devemos observar os balizamentos estabelecidos pelo STF considerando a noção de **dúvida objetiva** e a proibição da incidência de **erro grosseiro**. Vejamos.

Quanto à primeira indagação, “tendo em conta o **caráter subsidiário** da arguição de descumprimento de preceito fundamental — ADPF, consubstanciado no § 1.º do art. 4.º da Lei 9.882/1999, o Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de conhecer, como ação direta de inconstitucionalidade — ADI, a ADPF ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, em que se impugna a **Portaria 156/2005**, editada pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda do Pará, que estabeleceu, para fins de arrecadação do ICMS, novo boletim de preços mínimos de mercado para os

produtos que elenca em seu anexo único. Entendeu-se demonstrada a impossibilidade de se conhecer da ação como ADPF, em razão da **existência de outro meio eficaz para impugnação da norma**, qual seja a ADI, porquanto o objeto do pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade de **preceito autônomo** por ofensa a dispositivos constitucionais, restando observados os demais requisitos necessários à propositura da ação direta” (**ADPF 72 QO/PA**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.06.2005 — *Inf. 390/STF*).

Reafirmando esse entendimento, também, no sentido do conhecimento de ADPF como ADI (**princípio da fungibilidade** — art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 — e perfeita satisfação dos requisitos exigidos à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade — legitimidade ativa, objeto, fundamentação e pedido), cf. a reatuação da **ADPF 143** como **ADI 4.180-REF-MC** (j. 19.12.2008), bem como a reatuação da **ADPF 178** como **ADI 4.277** (j. 21.07.2009), tendo sido discutido, nesta última, o importante tema da união homoafetiva.

Em relação à segunda questão, o STF também admitiu que pedido formulado em ADI fosse conhecido como ADPF, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Muito embora outras problemáticas foram postas na causa, o dito “ponto jurídico mais nevrálgico e absorvente” consistia na discussão sobre a alteração de parâmetro de constitucionalidade pela EC n. 45/2004 e, assim, a discussão sobre a revogação ou não de lei anterior pela referida emenda. Assim, concluíram os Ministros do STF: “é lícito conhecer de ADI como ADPF, **quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela**” (**ADI 4.163**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.02.2012, Plenário, *DJE* de 1.º.03.2013).

O tema da fungibilidade veio a ser novamente discutido pela Corte no ano de 2014. No julgamento monocrático da **ADPF 158**, o Min. Gilmar Mendes não admitiu a fungibilidade por se tratar de situação clara para o cabimento de ADI; no caso, o objeto da ADPF era uma lei federal editada após a promulgação da CF/88. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário no julgamento do agravo regimental interposto (**ADPF 158 AgR/DF**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.

19.11.2014, Plenário, *DJE* de 02.02.2015).

Em outro julgado, o STF reafirmou que **dúvida razoável** sobre o caráter autônomo de atos infralegais, como decretos, resoluções e portarias, assim como **alterações supervenientes de normas constitucionais** poderiam justificar a **fungibilidade**. No caso concreto, porém, por se tratar de *lei ordinária federal* editada *depois da promulgação da CF/88*, **longe de envolver dúvida objetiva**, não configuraria a fungibilidade por se tratar de **erro grosseiro** na escolha do instrumento, violando, assim, o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 (**ADPF 314 AgR/DF**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2014, Plenário, *DJE* de 19.02.2015).

Estamos diante, portanto, da posição do STF sobre a aplicação do **princípio da fungibilidade** e, como bem colocou o Min. Marco Aurélio, da orientação conciliatória entre “**instrumentalidade** e **celeridades processuais**, de um lado, e **necessidade de não se baratear os institutos**, do outro”. De acordo com os precedentes citados, admite-se a fungibilidade quando se estiver diante de **dúvida razoável** sobre o “caráter autônomo de atos infralegais (...) como decretos, resoluções, portarias” ou em razão da “alteração superveniente da norma constitucional dita violada”. Fora essas hipóteses, caracterizado estará o **erro grosseiro** a afastar a aplicação da fungibilidade. Nesses termos, damos um claro exemplo de erro grosseiro, como verificado no precedente acima: impugnação de lei federal pós-constitucional por ADPF, quando cabível, no caso, indubitavelmente, a propositura de ADI.

■ 6.7.4. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

■ 6.7.4.1. Conceito (ADO)

Trata-se de inovação da CF/88, inspirada no art. 283 da Constituição portuguesa. O que se busca com a ADO é combater uma “doença”, chamada pela doutrina de “**síndrome de inefetividade das normas constitucionais**”.

O art. 103, § 2.º, da CF/88 determina que, declarada a inconstitucionalidade

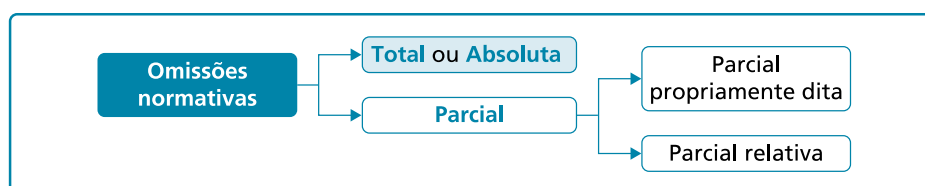
por omissão **de medida para tornar efetiva norma constitucional**, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. O que se busca é **tornar efetiva norma constitucional** destituída de efetividade, ou seja, somente as normas constitucionais de **eficácia limitada**!227

Nesse sentido, devendo o poder público ou órgão administrativo regulamentar norma constitucional de eficácia limitada e não o fazendo, surge a “doença”, a omissão, que poderá ser “combatida” por um “remédio” chamado ADO, de forma concentrada no STF.

Abrimos um pequeno parêntese, remetendo o leitor para o capítulo que trata dos **remédios constitucionais**, sugerindo o estudo conjunto da **ADO** com o do **mandado de injunção**, que também se caracteriza como um “remédio” cujo objetivo é combater a “síndrome de inefetividade das normas constitucionais”, de eficácia limitada. Na **ADO** temos o controle **concentrado**; através do **mandado de injunção**, o controle **difuso**, pela via de exceção ou defesa (cf. *item 14.11.5*).

Cabe mencionar, por último, a publicação da **Lei n. 12.063, de 27.10.2009**, que passou a estabelecer a disciplina processual da ADO e será apresentada nos itens seguintes.

■ 6.7.4.2. *Espécies de omissão*



A omissão poderá ser total ou parcial: **total**, quando não houver o cumprimento constitucional do dever de legislar; **parcial**, quando houver lei integrativa infraconstitucional, porém de forma insuficiente.

Como exemplo de **inconstitucionalidade por omissão total** ou **absoluta**, destacamos o art. 37, VII, que prevê o direito de greve para os servidores

públicos, ainda não regulamentado por lei. [228](#) Outro exemplo é o revogado art. 192, § 3.º, que dependia de lei (limitação da taxa de juros a 12% ao ano — cf. S. 648/STF e SV 7/2008).

A **inconstitucionalidade por omissão parcial**, por seu turno, poderá ser parcial propriamente dita ou parcial relativa.

Por **omissão parcial propriamente dita**, a lei existe mas regula de forma deficiente o texto. Como exemplo, temos o art. 7.º, IV, que dispõe sobre o direito ao **salário mínimo**. A lei fixando o seu valor existe, mas o regulamenta de forma deficiente, pois o valor fixado é muito inferior ao razoável para cumprir toda a garantia da referida norma.

Por fim, a **omissão parcial relativa** surge quando a lei existe e outorga determinado benefício a certa categoria mas deixa de concedê-lo a outra, que deveria ter sido contemplada. Nesse caso, tem prevalecido a Súmula 339/STF, potencializada com a sua conversão na **SV n. 37/2014**: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

■ 6.7.4.3. Objeto (ADO)

O art. 103, § 2.º, fala em “omissão de **medida**” para tornar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos **Poderes** ou de **órgão administrativo**.

Com precisão anota Barroso que a omissão é de cunho **normativo**, que é mais ampla do que a omissão de cunho *legislativo*. Assim, engloba “... atos gerais, abstratos e obrigatórios de outros Poderes e não apenas daquele ao qual cabe, precipuamente, a criação do direito positivo”.

A omissão, então, pode ser do **Poder Legislativo**, do **Poder Executivo** (atos secundários de caráter geral, como regulamentos, instruções, resoluções etc.), ou do próprio **Judiciário** (por exemplo, a omissão em regulamentar algum aspecto processual em seu Regimento Interno).

Portanto, continua Barroso, “... são impugnáveis, no controle abstrato da

omissão, a inércia legislativa em editar quaisquer dos atos normativos primários suscetíveis de impugnação em ação direta de inconstitucionalidade... O objeto aqui, porém, é mais amplo: também caberá a fiscalização da omissão inconstitucional em se tratando de atos normativos secundários, como regulamentos ou instruções, de competência do Executivo, e até mesmo, eventualmente, de atos próprios dos órgãos judiciários”.[229](#)

O STF já decidiu que, pendente julgamento de ADO, se a norma que não tinha sido regulamentada é revogada, a ação deverá ser extinta por perda de objeto.[230](#)

A mesma decisão, qual seja, pela perda de objeto, tomou o STF para a hipótese de encaminhamento de projeto de lei sobre a matéria ao Congresso Nacional (cf. ADI 130-2/DF), ou, ainda, pelo não cabimento da ação se, no momento de sua propositura, o processo legislativo já havia sido desencadeado (ADI 2.495, Rel. Ilmar Galvão, j. 02.05.2002, *DJ* de 02.08.2002).

Este último posicionamento, contudo, foi repensado no julgamento da **ADO 3.682**, entendendo o STF não se justificar a demora na apreciação de projetos já propostos (*inertia deliberandi* das Casas Legislativas), passível de se caracterizar uma desautorizada “conduta manifestamente **negligente** ou **desidiosa** das Casas Legislativas”, colocando em **risco a própria ordem constitucional** (voto do Min. Gilmar Mendes — tema discutido no *item* 6.7.4.9).

Por derradeiro, adotando posicionamento bastante formalista, sobre o qual deixamos a nossa crítica, o STF entendeu inexistente a fungibilidade da ADO com o mandado de injunção, tendo em vista a diversidade de pedidos: “Impossibilidade jurídica do pedido de conversão do mandado de injunção em ação direta de inconstitucionalidade por omissão” (**MI 395-QO**, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 11.09.1992).

■ 6.7.4.4. Competência (ADO)

O órgão competente para apreciar a ação direta de inconstitucionalidade por

omissão é o **STF**, de forma originária (art. 103, § 2.º, c/c, analogicamente, o art. 102, I, “a”).

■ 6.7.4.5. *Legitimidade (ADO)*

Os legitimados para a propositura da **ADO** são **os mesmos da ADI genérica**, ou seja, o rol previsto no art. 103, com as peculiaridades já apontadas em relação à **pertinência temática**.

A **Lei n. 12.063/2009** ratificou esse posicionamento, não havendo mais qualquer dúvida sobre a questão.

■ 6.7.4.6. *Natureza jurídica dos legitimados (ADO)*

Conforme anota o Min. Gilmar Mendes, assim como acontece na ADI genérica, o processo de controle na **ADO** tem por escopo a “defesa da ordem fundamental contra condutas com ela incompatíveis. Não se destina, pela própria índole, à proteção de situações individuais ou de relações subjetivadas, mas visa precipuamente à defesa da ordem jurídica”. Os legitimados agem como “**advogados do Interesse Público** ou, para usar a expressão de *Kelsen*, como **advogados da Constituição**”. Utilizando a denominação de *Triepel*, tem-se “típico **processo objetivo**” (voto na ADI 3.682).

■ 6.7.4.7. *Procedimento (ADO)*

O procedimento da **ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO)** é praticamente o mesmo da ADI genérica, com algumas peculiaridades.

Nos termos do art. 12-B da Lei n. 9.868/99, a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão e indicará:

a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever

constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa;

o pedido, com suas especificações.

A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, cabendo **agravo** da referida decisão.

Lembramos que, de acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Proposta a ação, não se admitirá desistência, devendo ser, no que couber, aplicadas as disposições constantes da Seção I do Capítulo II da Lei n. 9.868/99.

Os legitimados constantes do art. 103 da CF/88 poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais.

Modificando o entendimento do STF, [231](#) a lei passou a estabelecer que o relator **poderá** solicitar a manifestação do **AGU**, cujo encaminhamento deverá ser feito no prazo de 15 dias.

O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 dias, após o decurso do prazo para informações.

Finalmente, segundo Clèmerson Merlin Clève, “não há prazo para a propositura da ação. É evidente, entretanto, que sem o transcurso de um prazo razoável, aferível caso a caso, não haverá omissão inconstitucional censurável, mas sim mera lacuna técnica (omissão constitucional e omissão constitucional em trânsito para a inconstitucionalidade)”. [232](#)

■ 6.7.4.8. *Medida cautelar (ADO)*

Nesse ponto, a **Lei n. 12.063/2009** inovou a matéria, passando a admitir medida cautelar em **ADO**.

Segundo o art. 12-F da Lei n. 9.868/99, em caso de **excepcional urgência e relevância da matéria**, o STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus **membros**, observado o disposto no art. 22 (*quorum* de instalação da sessão de julgamento com no mínimo 8 Ministros), poderá **conceder medida cautelar, após** a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. [233](#)

A medida cautelar poderá consistir na **suspensão da aplicação da lei** ou do **ato normativo questionado**, no caso de **omissão parcial**, bem como **na suspensão de processos judiciais** ou de **procedimentos administrativos**, ou ainda em **outra providência a ser fixada pelo Tribunal**.

O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 dias.

No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma do previsto no Regimento do Tribunal.

Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar, em seção especial do *Diário Oficial da União* e do *Diário da Justiça da União*, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II da Lei n. 9.868/99.

■ 6.7.4.9. *Efeitos da decisão (ADO)*

Declarada a inconstitucionalidade, indagamos se o STF (Poder Judiciário) poderia elaborar a lei, para suprir a omissão.

Em respeito ao princípio da **tripartição dos Poderes**, insculpido no art. 2.º da CF/88, não é permitido ao Judiciário legislar (salvo nas hipóteses constitucionalmente previstas, como a elaboração de seu Regimento Interno).

O art. 103, § 2.º, estabelece efeitos diversos para o **poder competente** e para o **órgão administrativo**:

■ **poder competente**: será dada ciência ao poder competente, não tendo sido fixado qualquer prazo para a adoção das providências necessárias;

órgão administrativo: deverá suprir a omissão da medida no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, ou, na dicção do art. 12-H, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, em **prazo razoável** a ser estipulado **excepcionalmente** pelo Tribunal, tendo em vista as **circunstâncias específicas** do caso e o **interesse público** envolvido.

Neste ponto, o art. 103, § 2.º, poderia ser interpretado de duas maneiras: **a)** ou o prazo foi estabelecido apenas para o órgão administrativo, não podendo o STF fixar prazo para o Legislativo ou outro Poder omissor; **b)** ou o prazo pode ser fixado pelo Judiciário tanto para o órgão administrativo como para o Legislativo ou outro órgão omissor. Porém, se estabelecido para o órgão administrativo, deverá ser dentro de 30 dias e, agora, nos termos do art. 12-H, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, em **prazo razoável** a ser estipulado **excepcionalmente** pelo Tribunal, tendo em vista as **circunstâncias específicas** do caso e o **interesse público** envolvido.

Nesse sentido, o Min. Carlos Britto, no julgamento da **ADO 3.682**, observou, acompanhando o voto do Min. relator: “diferentemente da Constituição portuguesa, a nossa não se limitou a cuidar da ADI por omissão de medida legislativa; foi além. Quando a nossa Constituição falou em dar ciência ao poder competente, claro que mais de um poder, não só ao Poder Legislativo, apenas a Constituição avançou o comando de que, em se tratando de órgão administrativo, esse prazo seria de trinta dias, mas **sem com isso excluir a possibilidade de se fixar um prazo, logicamente, maior para o Poder Legislativo**” (grifamos).

O tema, nessa linha, foi **amplamente revisto pelo STF** no precedente citado

(e de *indispensável leitura para as provas e concursos*), no qual se discutiu a inércia do legislador em elaborar a LC federal, prevista nos termos do art. 18, § 4.º, na redação dada pela EC n. 15/96, fixando o procedimento de criação dos novos Municípios (cf. *item 7.6.1*).

Como se sabe, a EC n. 15/96, alterando a redação do art. 18, § 4.º, foi publicada em 13.09.1996. Apesar de fazer quase 20 anos, a lei complementar federal ainda não é uma realidade, mostrando-se, portanto, flagrante a omissão. (Lembramos que, apesar de ter o Congresso Nacional aprovado projeto de lei complementar disciplinando a matéria, este foi vetado pela Presidente da República Dilma Rousseff mais de uma vez. O último, nos mesmos termos de veto anterior, de acordo com a *mensagem n. 250/2014*, teve por fundamento o dito **interesse público**: “depreende-se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que haja a correspondente geração de novas receitas”).

O Min. Relator, Gilmar Mendes, no julgamento da citada ADO 3.682, à época antes da aprovação dos mencionados projetos de lei (que, aliás, como visto, foram **todos vetados**), estabeleceu: “... apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4.º, da Constituição, é possível constatar a **omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência**. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, **não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas**, conduta esta que pode pôr em **risco a própria ordem constitucional**. A ***inertia deliberandi*** das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4.º, da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da lei complementar federal”.

Pelo que se observa do voto do Min. Gilmar Mendes, no direito alemão, com o objetivo de afastar as omissões legislativas, várias técnicas surgiram, como

aquela que declara a **inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade** (*Unvereinbarerklärung*), ou aquela de **apelo ao legislador** (*Appellentscheidung*), esta última “... decisão na qual se afirma que a situação jurídica em apreço ainda se afigura constitucional, devendo o legislador empreender as medidas requeridas para evitar a consolidação de um estado de inconstitucionalidade”, tudo para se evitar uma inconcebível situação de “autêntico caos jurídico”.

E conclui: “o princípio do Estado de Direito (art. 1.º), a cláusula que assegura a imediata aplicação dos direitos fundamentais (art. 5.º, § 1.º) e o disposto no art. 5.º, LXXI, que, ao conceder o mandado de injunção para garantir os direitos e liberdades constitucionais, impõe ao legislador o dever de agir para a concretização desses direitos, exigem ação imediata para eliminar o estado de inconstitucionalidade”.

Assim, a ação foi julgada “... procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4.º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI n. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios” (**ADO 3.682**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.05.2007, *DJ* de 06.09.2007).

Muito embora a *ementa* acima reproduzida não indique o caráter coercitivo da decisão do STF (“*não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável*”), a leitura do acórdão [234](#) e suas discussões finais nos dava a ideia de que, em razão do **caráter mandamental** da decisão, o Congresso Nacional teria de legislar dentro de tal período de 18 meses, prazo, inclusive, fixado no

dispositivo do acórdão.

Em não elaborando a lei, dado o caráter mandamental, consequências processuais poderiam decorrer e, ainda, parece-nos que se poderiam aplicar, por analogia, o art. 64 e seus parágrafos (CF/88), com a ideia de travamento de pauta, ou, quem sabe, diante da evolução da jurisprudência do STF no controle das omissões legislativas (**MI 712** — cf. *item 14.11.5.4*), o suprimimento da omissão pelo próprio STF.

Questionando os efeitos práticos da **ADO 3.682**, em 11.09.2008, o Presidente da Câmara dos Deputados encaminhou o *Ofício n. 1073/2008/SGM/P*, de 02.09.2008, ao Presidente do STF, dizendo não ter tomado conhecimento de decisão que “obrigasse” o Parlamento a elaborar a LC, assim como alertando sobre o risco de a decisão do STF violar o **princípio da separação de Poderes** (art. 2.º da CF/88), caso fosse realmente impositiva a decisão proferida.

Cabe notar, contudo, que, restringindo nossa opinião, o **Min. Presidente do STF** determinou, em **12.09.2008**, por meio do *Ofício n. 346/GP*, fosse oficiado o Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhando o inteiro teor do acórdão de fls. 132-187, e esclareceu: **“não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI ns. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios”**.

Deixou claro, no entanto, que findo o prazo de 24 meses e não resolvida a situação dos Municípios criados violando a regra contida no art. 18, § 4.º, eles desapareceriam, restabelecendo a situação anterior.

Para tentar resolver esse impasse, o CN promulgou a **EC n. 57/2008**, que acrescentou o art. 96 ao ADCT: “ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação

do respectivo Estado à época de sua criação”.

Percebe-se que referida EC busca convalidar o vício formal de todas as leis estaduais que criaram Municípios sem a observância do art. 18, § 4.º, “constitucionalizando”, de maneira **ilegítima**, leis que nasceram inconstitucionais.

Parece-nos bem complicado aceitar que Municípios que foram criados, alguns até, por exemplo, sem o plebiscito adequado, sem um rigoroso estudo de viabilidade, sejam convalidados por emenda constitucional em um “gritante” e imoral mecanismo de **constitucionalidade superveniente**.

Em nosso entender, a EC foi contra a decisão do STF que fazia um “apelo” para se elaborar a lei complementar e, uma vez elaborada, a decisão do STF era no sentido de se corrigir o vício apontado, dando oportunidade para que os Municípios criados preenchessem todos os requisitos constantes do art. 18, § 4.º.

Foi por esse motivo que o STF fixou um prazo distinto na modulação dos efeitos.

Lembrando, o apelo era para o Congresso Nacional fazer a lei em 18 meses e, em relação aos Municípios, foi fixado o prazo de 24 meses de sobrevida. Essa diferença de 6 meses seria para que o Município corrigisse o vício formal de inconstitucionalidade, e, se nada fizesse, findo o prazo maior de 24 meses, implacavelmente, o Município desapareceria. Sem dúvida, novamente, insistimos, a EC mostra-se ilegítima e inconstitucional.

Resta saber como o STF interpretará essa questão se, eventualmente, a EC n. 57/2008 vier a ser objeto de futura ADI (**matéria pendente**).

Temos observado que os municípios que foram criados a partir de 31.12.2006, data estabelecida pela emenda, não estão sendo preservados pelo STF, já que referida emenda convalidou expressamente apenas aqueles que foram efetivamente criados até aquela data, conforme se observa pelo comando contido no art. 96 do ADCT (cf. **ADI 4.992**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.09.2014, Plenário, *DJE* de 13.11.2014).

Alertamos, contudo, que, em determinado caso concreto, o STF acabou

aceitando os termos da referida emenda, o que, com o máximo respeito, pelos motivos expostos, não entendemos ter sido a melhor decisão, até porque entendemos que a EC n. 57/2008, além de ser imoral, é flagrantemente inconstitucional por violar a regra contida no art. 18, § 4.º, CF/88. Vejamos:

“EMENTA: Criação do Município de Pinto Bandeira/RS. **Ação julgada prejudicada pela edição superveniente da EC 57/2008**. Alegação de contrariedade à EC 15/96 (...). Com o advento da EC 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. A Lei 11.375/99 foi publicada nos termos do art. 9.º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela EC 20/97, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada” (**ADI 2.381-AgR**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.2011, Plenário, *DJE* de 11.04.2011).

Finalmente, destacamos importante decisão tomada pelo Min. Dias Toffoli, no julgamento monocrático do pedido de medida cautelar na **ADO 24** (j. 1.º.07.2013 — *pendente de julgamento*).

O art. 27 da EC n. 19/98 estabelece o prazo de **120 dias** para que o Congresso Nacional **elabore a lei de defesa do usuário de serviços públicos**; aliás, um tema extremamente importante quando se pensa nos serviços de saúde, educação, transporte, assistência social etc.

Passados **mais de 15 anos**, a lei (que deveria ter sido editada em 120 dias!) ainda não foi elaborada, apesar da existência de projetos de lei tramitando (PLC n. 6.953/2002, substitutivo do PL n. 674/99).

Trata-se de mais um exemplo de **inatividade legislativa** e, no caso, por existirem os projetos de lei, de *inertia deliberandi* (discussão e votação).

Em sua decisão, de maneira acertada, o Ministro entendeu que a **inércia** na apreciação dos projetos de lei se mostrava **inaceitável**, já que **manifesta a omissão** a caracterizar afronta à Constituição (e, por que não dizer, nas palavras do Min. Gilmar Mendes, no julgamento da ADO 3.682, **omissão negligente e desidiosa a colocar em risco a própria ordem constitucional**).

Dessa forma, acolhendo o pedido formulado pela OAB, fixou o prazo de 120

dias para que o Congresso Nacional elabore a lei.

No fechamento desta edição do livro, a lei ainda não havia sido aprovada, apesar de já esgotado o prazo. Resta aguardar como o STF definirá essa questão e, quem sabe, seja essa a oportunidade para evoluir a jurisprudência **tímida** em relação à eficiência da ADO. O **parecer n. 3.455/2014 da PGR** é pela “confirmação da cautelar concedida monocraticamente e, em definitivo, pela procedência parcial do pedido, para declarar a omissão do Congresso Nacional na edição da lei de defesa do usuário de serviços públicos, prevista no art. 27 da EC n. 19/98, com estabelecimento de prazo razoável para sua aprovação”.

Novamente, como sugestão, parece razoável que a técnica que vem sendo utilizada no MI também possa ser aqui aplicada, especialmente em casos, como esse, de **inércia desrespeitosa**. Assim, plausível o pedido feito pela OAB de aplicação subsidiária do CDC enquanto não editada a lei, como forma de se “resguardar minimamente o cidadão contribuinte em suas relações com o Poder Público”.

■ 6.7.4.10. A atual jurisprudência do STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO?

SIM.

Pedimos vênia para transcrever a ementa do precedente, recomendando a leitura do voto do Min. Gilmar Mendes, bem como a análise da discussão por nós exposta no *item 6.7.2.10* deste estudo, tendo o STF estabelecido alguns parâmetros:

“EMENTA: Senhores Ministros, Senhoras Ministras. Estamos diante de um caso deveras interessante. Temos quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADI n. 1.987/DF, ADI n. 875/DF, ADI n. 2.727/DF e ADI n. 3.243/DF) imbricadas por uma evidente relação de conexão, fenômeno que determina o seu **julgamento conjunto**, conforme a jurisprudência desta Corte (**ADI-MC n. 150**, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* 9.3.1990). Por outro lado, é possível observar a intenção dos requerentes de estabelecer uma nítida **distinção de pedidos**: uns pela declaração da inconstitucionalidade por

omissão e outros pela declaração da inconstitucionalidade (por ação). (...) O quadro aqui revelado, portanto, está a demonstrar uma **clara imbricação de pedidos e causas de pedir** e, dessa forma, a **evidenciar a patente fungibilidade que pode existir entre a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão**. (...) A Lei n. 9.868/99 possui capítulos específicos para a ação direta de inconstitucionalidade (Capítulo II) e para a ação declaratória de constitucionalidade (Capítulo III). Com a nova Lei n. 12.063, de 22 de outubro de 2009, a Lei n. 9.868/99 passa a contar com o capítulo II-A, que estabelece rito procedimental e medidas cautelares específicas para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A Lei n. 9.882/99, por seu turno, trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental. No Supremo Tribunal Federal, atualmente, todas as ações possuem uma classe específica de autuação: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI); Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). **Portanto, ante a aparente confusão inicialmente verificada nos diversos pedidos, como demonstrado, e tendo em vista a patente defasagem da jurisprudência até então adotada pelo Tribunal, temos aqui uma valiosa oportunidade para superarmos o antigo entendimento e reconhecermos o caráter fungível entre as ações”** (ADI 875; ADI 1.987; ADI 2.727, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2010, Plenário, DJE de 30.04.2010).

■ 6.7.5. Representação interventiva (IF)

■ 6.7.5.1. Conceito (IF)

O art. 18, *caput*, da CF/88 estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**. Vale dizer, como regra geral, nenhum ente federativo deverá intervir em qualquer outro.

Excepcionalmente, no entanto, a CF prevê situações (de anormalidade) em que poderá haver a intervenção:

■ **União** nos **Estados, Distrito Federal** (hipóteses do art. 34) e nos **Municípios localizados em Território Federal**²³⁵ (hipótese do art. 35); **Estados** em seus **Municípios** (art. 35).

A **representação interventiva**, que surgiu, conforme visto, com a Constituição de 1934, apresenta-se como um dos pressupostos para a decretação da intervenção federal, ou estadual, pelos Chefes do Executivo, nas hipóteses contempladas na CF/88.²³⁶ Assim, reforça-se, nessa modalidade de procedimento, quem decreta a intervenção não é o Judiciário, mas o Chefe do Poder Executivo.

Clèmerson Clève, ao analisar o instituto, conclui tratar-se de “... procedimento fincado a meio caminho entre a fiscalização da lei *in thesi* e aquela realizada *in casu*. Trata-se, pois, de uma variante da fiscalização concreta realizada por meio de ação direta”.²³⁷

O Judiciário exerce, assim, um controle da **ordem constitucional** tendo em vista o **caso concreto** que lhe é submetido à análise.

Nesse sentido, Barroso observa que “... embora seja formulado um juízo de certa forma abstrato acerca da constitucionalidade do ato normativo — nas hipóteses em que o ato impugnado tenha essa natureza (e, acrescente-se, veremos que o objeto não se resume a ato normativo) — não se trata de processo objetivo, sem partes ou sem um caso concreto subjacente. Cuida-se, sim, de um **litígio constitucional**, de uma **relação processual contraditória**, contrapondo União e Estado-membro, cujo desfecho pode resultar em intervenção federal”.²³⁸

O Judiciário não nulifica o ato, mas apenas verifica se estão presentes os pressupostos para a futura decretação da intervenção pelo Chefe do Executivo.

Poderíamos pensar, então, em 3 fases do procedimento, estudadas a seguir:

FASE 1	FASE 2	FASE 3
--------	--------	--------

■ fase jurisdicional: o STF ou TJ analisam apenas os pressupostos para a intervenção, não nulificando o ato que a ensejou. Julgando procedente o pedido, requisitam a intervenção para o Chefe do Executivo	■ intervenção branda: o Chefe do Executivo, por meio de decreto, limita-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade ■ controle político? NÃO. Nesta <i>fase 2</i>, está dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa	■ intervenção efetiva: se a medida tomada durante a <i>fase 2</i> não foi suficiente, o Chefe do Executivo decretará a efetiva intervenção, devendo especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor ■ controle político? SIM. Nesta <i>fase 3</i>, deverá o decreto do Chefe do Executivo ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas, sendo que, estando em recesso, será feita a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas
--	--	---

■ 6.7.5.2. *Representação interventiva federal (ADI interventiva federal)*

O art. 36, III, da CF/88, primeira parte, estabelece que a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo **STF**, de representação do **Procurador-Geral da República**, na hipótese do **art. 34, VII**, quais sejam, os **princípios sensíveis da Constituição**.

Durante a vigência do texto de 1988, jamais se passou da *fase 1* (judicial) para a *fase 2* (decretação pelo Chefe do Poder Executivo), muito embora alguns poucos pedidos de intervenção, com base no art. 36, III, destacando-se:

- **IF 114 (07.02.1991):** pedido de intervenção em razão de omissão do poder público no controle de **linchamento de presos** no Estado de Mato

Grosso. No mérito, o STF entendeu que não era caso de intervenção, indeferindo, portanto, o pedido;

■ **IF 4.822** (08.04.2005): pedido de intervenção no *Centro de Atendimento Juvenil Especializado (Caje)*, com base em deliberação do *Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH)*, que condenou a sua estrutura física e gerencial (**matéria pendente de julgamento pelo STF**);

■ **IF 5.129** (05.10.2008): pedido de intervenção formulado pelo PGR contra o estado de Rondônia, por suposta violação a direitos humanos no **presídio Urso Branco**, em Porto Velho, que se encontra em situação de “calamidade”. Segundo o então PGR, Antonio Fernando Souza, “... nos últimos oito anos contabilizaram-se mais de cem mortes e dezenas de lesões corporais [contra presos], fruto de motins, rebeliões entre presos e torturas eventualmente perpetradas por agentes penitenciários” (*Notícias STF*, 08.10.2008) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**);

■ **IF 5.179** (11.02.2010): pedido de intervenção por suposto esquema de corrupção no DF. Conforme relatado a seguir, no mérito, o pedido foi julgado improcedente.

■ 6.7.5.2.1. Objeto (IF)

Apesar de, em um primeiro momento, o STF, mesmo diante de doutrina em sentido contrário (Alfredo Buzaid²³⁹), ter limitado o objeto da ação somente a atos normativos (**Rp 94/DF**, Rel. Min. Castro Nunes, j. 17.07.1946), o entendimento atual é o **mais amplo possível**, podendo ser objeto da ação:

■ **lei ou ato normativo que viole princípios sensíveis**;

■ **omissão ou incapacidade** das autoridades locais para assegurar o cumprimento e preservação dos princípios sensíveis, por exemplo, os direitos da pessoa humana;

■ **ato governamental estadual** que desrespeite os princípios sensíveis;

■ **ato administrativo que afronte os princípios sensíveis**;

ato concreto que viole os princípios sensíveis.

A **fase judicial** da intervenção não se confunde com a fase judicial das demais ações de inconstitucionalidade, pois, como visto, na ADI Interventiva (ou, por alguns, denominada **representação interventiva**), o Tribunal **não** nulificará, na **hipótese de lei**, o ato normativo.

Em relação à **omissão**, trata-se de importante avanço, já sugerido pela doutrina e, posteriormente, sedimentado na jurisprudência do STF, bem como na **Lei n. 12.562/2011**.

Como exemplo, citamos situação em que presos no Estado do Mato Grosso, por omissão estatal e negligência, estavam sendo **linchados** pela população local, revoltada com a gravidade dos crimes praticados.

Naturalmente, o STF entendeu que a omissão e a incapacidade do governo local em garantir o direito de presos (**direitos da pessoa humana**) já seriam suficientes para o cabimento da ação. Nesse sentido:

“Representação do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção federal no Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos ‘direitos da pessoa humana’, em face de **fato criminoso praticado com extrema crueldade** a indicar a inexistência de ‘condição mínima’, no Estado, ‘para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, que é o direito à vida’. (...) Hipótese em que estão em causa ‘direitos da pessoa humana’, em sua compreensão mais ampla, revelando-se **impotentes as autoridades policiais locais** para manter a **segurança** de três presos que acabaram subtraídos de sua proteção, por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, sendo mortos com requintes de crueldade. Intervenção federal e restrição à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo. Excepcionalidade da medida interventiva.” No tocante ao mérito do STF, contudo, embora a gravidade dos fatos, negou provimento ao pedido já que o Estado de Mato Grosso estaria procedendo a apuração do crime (**IF 114**, Rel. Min. Presidente Néri da Silveira, j. 13.03.1991).

O pedido de intervenção, conforme já referimos, também poderá envolver o DF, em razão de lei ou ato normativo, omissão ou ato governamental **distrital**.

Nessa linha, destacamos, para exemplificar, pedido de intervenção em razão de **ato governamental** a sugerir suposto “esquema de corrupção”, preservado, segundo o pedido formulado, por omissão das autoridades locais. [240](#)

Estamos nos referindo à IF 5.179, tendo sido o pedido formulado pelo PGR com base no art. 34, VII, “a”, por suposta violação aos **princípios republicano e democrático**, bem como ao **sistema representativo** (CF, art. 34, VII, “a”).

O pedido de intervenção federal fundou-se na “... **alegação** da existência de **esquema de corrupção** que envolveria o ex-Governador do DF, alguns Deputados Distritais e suplentes, investigados pelo STJ, e cujo concerto estaria promovendo a desmoralização das instituições públicas e comprometendo a higidez do Estado Federal. Tais fatos revelariam conspícua **crise institucional** hábil a colocar em risco as atribuições político-constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo e provocar instabilidade da ordem constitucional brasileira. (...) **No mérito**, entendeu-se que o perfil do momento político-administrativo do Distrito Federal já **não autorizaria a decretação de intervenção federal**, a qual se revelaria, agora, **inadmissível** perante a **dissolução do quadro que se preordenaria a remediar...**”, tendo ficado vencido o Min. Ayres Britto (IF 5.179, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30.06.2010, Plenário, DJE de 08.10.2010 e Inf. 593/STF).

Em face da gravidade dos fatos expostos na inicial, muito embora o **indeferimento** do pedido de intervenção acima relatado, vale a pena reproduzir passagens do voto **vencido** do Min. Ayres Britto (que pode ser lido na íntegra, uma vez que já publicado o referido acórdão):

“O Distrito Federal padece de **leucemia ética, democrática e cívica**, pelas suas cúpulas no âmbito do Legislativo e do Executivo. O caso é de **hecatombe institucional**. E aí, serve como luva encomendada essa **ferramenta** chamada de **intervenção**”, disse Ayres Britto.

Gurgel pediu a intervenção após ser deflagrada uma crise política na capital federal a partir de operação da Polícia Federal que investigou denúncias de corrupção, formação de quadrilha, desvio de verbas públicas e fraude em licitações no governo do DF.

Ayres Britto afirmou que a máquina administrativa distrital ainda padece de **deficiências graves**, mesmo após a eleição indireta do governador Rogério Rosso (PMDB) e que o Poder Legislativo ainda se encontra em estado de **letargia**, de não funcionamento. ‘A mentalidade dos governantes nos dois Poderes, Executivo e Legislativo, não mudou, permanece’, ponderou. ‘O caso é de cultura antirrepublicana de governo. Daí a necessidade da intervenção federal’.

Ele acrescentou ainda que há ‘provas robustas’, com fitas e depoimentos que evidenciam a situação de corrupção na capital federal, mas ressaltou que essa situação é, na verdade, um sintoma. ‘A causa da corrupção, dos desvios administrativos, de tantos conluíus espúrios está em uma **cultura antirrepublicana** que se instalou no Distrito Federal de longa data. Uma cultura antirrepublicana de governo que não é de agora’, afirmou.

Ele destacou a importância do Distrito Federal perante a nação, por ser a capital da República, como mais uma razão para a intervenção, e foi taxativo: ‘O bom exemplo republicano, representativo, democrático, ético tem que partir de Brasília. O bom exemplo vem de cima’.

‘Acho que a oportunidade é excelente para se fazer uma **profilaxia**. Não para cassar o Distrito Federal. Na verdade, se trata de **libertar o Distrito Federal das garras de um perigosíssimo esquema de enquadramento para assaltar o erário**’, concluiu Ayres Britto” (cf. *Notícias STF*, 30.06.2010).

■ 6.7.5.2.2. **Princípios sensíveis**

Cabe o pedido de intervenção, já referimos, quando houver violação aos denominados **princípios sensíveis**, que estão expostos no art. 34, VII, “a”-“e”:

- forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- direitos da pessoa humana;
- autonomia municipal;
- prestação de contas da Administração Pública, direta e indireta;
- aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e nos serviços públicos de saúde.

■ 6.7.5.2.3. Competência (IF)

Na hipótese de **representação interventiva federal**, a competência é **originária** do **STF** (art. 36, III).

■ 6.7.5.2.4. Legitimidade (IF)

O **único** e **exclusivo** *legitimado ativo* para a propositura da **representação interventiva federal** é o **Procurador-Geral da República**, que tem total **autonomia** e **discricionariedade** para formar o seu convencimento de ajuizamento.

Já se sustentou atuar ele como representante da União, chegando, outros, a sugerir, no entanto, que essa atribuição fosse transferida, por emenda, para o AGU.

Contudo, não nos parece adequado nem a ideia de representação da União, em virtude da regra constante no art. 129, IX, que veda, expressamente, por parte do Ministério Público, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, nem mesmo a transferência dessa atribuição para o AGU.

O entendimento que deve ser adotado é o de que o **PGR** atua em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sobretudo, no caso, a defesa do **equilíbrio federativo**.

Legitimado passivo deve ser entendido como o **ente federativo** no qual se verifica a violação ao princípio sensível da CF/88, devendo ser solicitadas informações às autoridades ou aos órgãos estaduais ou distritais responsáveis, como a Assembleia Legislativa local ou o Governador, neste último caso representado pelo Procurador-Geral do Estado ou do DF (art. 132 da CF/88).

Verifica-se, assim, uma **relação processual controvertida** entre a União e os Estados-Membros ou o DF.

■ 6.7.5.2.5. Procedimento (IF)

O procedimento da **representação interventiva federal** estava previsto na **Lei n. 4.337, de 1.º.06.1964**, assim como nos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.038/90 e nos arts. 350 a 354 do *RISTF*.

Contudo, cabe alertar a publicação da **Lei n. 12.562, de 23.12.2011**, regulamentando o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o STF.

Proposta a ação pelo Procurador-Geral da República, no STF, a petição inicial deverá conter:

a indicação do **princípio constitucional** sensível (art. 34, VII, da CF/88) que se considera violado ou, se for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas (esta última hipótese será tratada no *capítulo 7*, no item sobre *intervenção federal*);

a indicação do **ato normativo**, do **ato administrativo**, do **ato concreto** ou da **omissão** questionados;

a **prova** da **violação do princípio constitucional** ou da recusa de execução de lei federal;

o **pedido**, com suas especificações.

A petição inicial será apresentada em 2 vias, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado (**estadual** ou **distrital**) e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Incumbe ao relator **indeferir liminarmente a petição inicial** quando:

não for o caso de representação interventiva;

faltar algum dos requisitos estabelecidos na lei;

for inepta.

Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá **agravo**, no prazo de **5 dias**.

Entendemos que essa regra prevista no art. 4.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011, vai ser revogada pelo CPC/2015 quando este estiver em vigor.

De acordo com o Novo Código, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno**

para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir (**administrativamente**) o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários, na forma do regimento interno.

Não solucionado o problema e não sendo caso de arquivamento, apreciado eventual pedido de liminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as **informações** às **autoridades responsáveis pela prática do ato questionado**, que as prestarão em até **10 dias**.

Decorrido o prazo para prestação das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o **AGU** e o **PGR**, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de **10 dias**.

O relator, se entender necessário, poderá **requisitar informações adicionais**, **designar perito** ou **comissão de peritos** para que elabore laudo sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em **audiência pública**, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Poderão ser autorizadas, ainda, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo, reconhecendo-se, assim, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011, a manifestação de ***amicus curiae***.

Vencidos os prazos ou, se for o caso, realizadas as diligências, o relator lançará o relatório, com cópia para todos os Ministros e pedirá dia para julgamento.

A **decisão** sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos **8 Ministros** (*quorum* de instalação da sessão de julgamento, como se verifica, também, na ADI), devendo ser proclamada a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação

interventiva se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 Ministros (**maioria absoluta**).

Estando ausentes Ministros em número que possa influir na decisão sobre a representação interventiva, o julgamento será **suspenso**, a fim de se aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão.

Julgado procedente o pedido, far-se-á a comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final for pela **procedência do pedido** formulado na representação interventiva, o Presidente do STF, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do **Presidente da República** para, no **prazo improrrogável de até 15 dias**, dar cumprimento aos §§ 1.º e 3.º do art. 36 da Constituição Federal.

Dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção especial do *Diário da Justiça* e do *Diário Oficial da União*.

Por se tratar de “**requisição**”, e não mera solicitação, o Presidente da República não poderá descumprir a **ordem mandamental**, sob pena de cometimento tanto de crime comum como de responsabilidade, devendo, então, decretar a intervenção (por nós denominada, nesta agora *fase 2* — *vide* quadro *supra*, item 6.7.5.1 —, **intervenção branda**).

O Presidente da República, nos termos do art. 36, § 3.º, por meio de **decreto**, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado. Caso essa medida não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, aí, sim, o **Presidente da República decretará** a intervenção federal (*fase 3* — **intervenção efetiva**).

Nesse último caso, o **decreto de intervenção**, que especificará a **amplitude**, o **prazo** e as **condições de execução** e que, **se couber**, **nomeará** o **interventor** afastando as autoridades responsáveis de seus cargos (art. 84, X, CF/88), será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas (**controle político**). Se o Congresso Nacional não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas (art. 36, §§ 1.º e 2.º, CF/88).

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo por impedimento legal (art. 36, § 4.º, CF/88).

Cabe alertar que a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva é:

- **irrecorrível;**

- **insuscetível de impugnação por ação rescisória.**

■ **6.7.5.2.6. Medida liminar (IF)**

Barroso chegou a sustentar que “a natureza e a finalidade da ação direta interventiva **não são compatíveis com a possibilidade de concessão de medida liminar**. Não há como antecipar qualquer tipo de efeito, como a eventual suspensão do ato impugnado, uma vez que a própria decisão de mérito tem como consequência apenas a determinação de que o Chefe do Executivo execute a intervenção”.[241](#)

Cumprе lembrar, contudo, que o art. 2.º da Lei n. 5.778/72, que regula o processo da *representação interventiva estadual*, estabelece que o relator da representação poderá, a requerimento do chefe do Ministério Público estadual e mediante despacho fundamentado, **suspender liminarmente o ato impugnado**.

Anteriormente, o *art. 5.º da Lei n. 4.337/64* previa um *procedimento abreviado* para a análise do pedido.

Finalmente, o *art. 5.º da Lei n. 12.562/2011* **admitiu expressamente o cabimento de medida liminar na representação interventiva**, mas somente por decisão da **maioria absoluta** dos Ministros.

Parece que a não previsão de concessão de medida liminar pelo Relator ou pelo Ministro Presidente do STF (diferente das outras ações de controle) vai ao encontro da preocupação lançada por Barroso e da gravidade dos efeitos da decisão em relação à Federação.

Para concessão da liminar, o relator **poderá** ouvir os órgãos ou autoridades

responsáveis pelo ato questionado, bem como o AGU ou o PGR, no prazo comum de 5 dias.

A liminar poderá consistir na determinação de que se **suspenda o andamento de processo** ou **os efeitos de decisões judiciais** ou **administrativas** ou **de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva**.

■ 6.7.5.2.7. *Representação interventiva no caso de recusa à execução de lei federal*

O art. 36, III, estabelece o cabimento de **representação interventiva** perante o **STF**, a ser ajuizada pelo **PGR**, no caso de **recusa à execução de lei federal** por parte de Estado-Membro ou do Distrito Federal (art. 34, VI, 1.^a parte).

Gilmar Mendes prefere falar em **“recusa à execução do direito federal”**,²⁴² o que também entendemos mais adequado.

Relembramos que, originalmente, o texto de 1988 falava em competência do STJ, equívoco este corrigido pela *Reforma do Judiciário* (EC n. 45/2004), que, acertadamente, deixou claro ser competência do **STF**, até porque, no fundo, o que se tem é um conflito entre a União e o Estado ou a União e o DF (que descumprem ou não aplicam o direito federal), incidindo, assim, a regra do **art. 102, I, “f”**, da CF/88, e, portanto, a competência do STF.

O procedimento está previsto, igualmente, na **Lei n. 12.562/2011**, e tudo o que se falou acima se aplica à hipótese.

A doutrina tem-se limitado a tratar como ADI Interventiva (admitindo-se essa nomenclatura ainda como adequada) a hipótese do art. 34, VII (violação aos princípios sensíveis), e, assim, remetemos o nosso ilustre leitor para a temática da *intervenção federal estudada no capítulo 7 (item 7.12)*.

■ 6.7.5.3. *Representação interventiva estadual (ADI interventiva estadual)*

O processo da **representação interventiva estadual** está regulamentado na

Lei n. 5.778/72, que, em seu art. 1.º, *caput*, estabelece que o processo e o julgamento das representações interventivas estaduais em Municípios regulam-se, no que for aplicável, pela **Lei n. 4.337/64**, excetuado o seu art. 6.º (que tinha a seguinte redação: “*só caberão embargos, que se processarão na forma da legislação em vigor, quando, na decisão, forem 3 (três) ou mais os votos divergentes*”).

Alertamos, contudo, que, com o advento da **Lei n. 12.562/2011**, que tratou de toda a matéria, a nosso ver, a Lei n. 4.337/64 foi totalmente revogada e, assim, o procedimento deverá observar, no que couber, as novas regras introduzidas pela referida Lei n. 12.562/2011.

O art. 35, IV, da CF/88, por sua vez, dispõe que a intervenção estadual, a ser decretada pelo **Governador de Estado**, dependerá de provimento pelo **TJ local** de representação para assegurar a observância de princípios indicados na CE, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. As regras vêm previstas nas Constituições estaduais e nos regimentos internos dos tribunais locais, devendo, em essência, por **simetria**, seguir o **modelo federal**, de acordo com o seguinte quadro:

	ADI INTERVENTIVA FEDERAL	ADI INTERVENTIVA ESTADUAL
Fase 1 — “Judicial”		
OBJETO	■ Lei ou ato normativo, ou omissão, ou ato governamental estaduais ou distritais que desrespeitem os princípios sensíveis previstos no art. 34, VII, “a”-“e”, da CF/88	■ Lei ou ato normativo, ou omissão, ou ato governamental municipais que desrespeitem os princípios sensíveis indicados na CE
COMPETÊNCIA	■ STF — originária	■ TJ — originária

LEGITIMADO ATIVO	■ PGR — Chefe do Ministério Público da União (art. 129, IV, da CF/88)	■ PGJ — Chefe do Ministério Público Estadual (art. 129, IV, da CF/88)
LEGITIMADO PASSIVO	■ Ente federativo (Estado ou DF) no qual se verifica a violação ao princípio sensível da CF/88, devendo ser solicitadas informações às autoridades ou aos órgãos estaduais ou distritais responsáveis pela violação aos princípios sensíveis	■ Ente federativo (Município) no qual se verifica a violação ao princípio sensível da CE, devendo ser solicitadas informações às autoridades ou aos órgãos municipais responsáveis pela violação aos princípios sensíveis
PROCEDIMENTO	■ Proposta a ação pelo Procurador-Geral da República, no STF, quando a lei ou o ato normativo de natureza estadual (ou distrital), ou omissão, ou ato governamental contrariarem os princípios sensíveis da CF, buscar-se-á a solução administrativa ■ Não sendo o caso, nem o de arquivamento, serão solicitadas informações às autoridades estaduais ou distritais responsáveis e ouvido o PGR, sendo, então, o pedido relatado e levado a julgamento	■ Proposta a ação pelo Procurador-Geral de Justiça, no TJ, quando a lei ou o ato normativo, ou omissão, ou ato governamental de natureza municipal contrariarem os princípios sensíveis previstos na CE, buscar-se-á a solução administrativa ■ Não sendo o caso, nem o de arquivamento, serão solicitadas informações às autoridades municipais responsáveis e ouvido o PGJ, sendo, então, o pedido relatado e levado a julgamento ■ Julgado procedente o pedido

	■ Julgado procedente o pedido (<i>quorum</i> do art. 97, maioria absoluta), o Presidente do STF imediatamente comunicará a decisão aos órgãos do Poder Público interessados e requisitará a intervenção ao Presidente da República, que, por se tratar de “requisição”, e não mera solicitação, não poderá descumprir a ordem mandamental, sob pena de cometimento tanto de crime comum como de responsabilidade, inaugurando-se, assim, a <i>fase 2</i> do procedimento	(<i>quorum</i> do art. 97, maioria absoluta), o Presidente do TJ imediatamente comunicará a decisão aos órgãos do Poder Público interessados e requisitará a intervenção ao Governador do Estado, que, por se tratar de “requisição”, e não mera solicitação, não poderá descumprir a ordem mandamental, sob pena de cometimento tanto de crime comum como de responsabilidade, inaugurando-se, assim, a <i>fase 2</i> do procedimento
Fase 2 — “Intervenção Branda”		
DECRETO DO EXECUTIVO	■ O Presidente da República, nos termos do art. 36, § 3.º, por meio de decreto, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade ■ Nessa fase, está dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional (controle político)	■ O Governador do Estado, nos termos do art. 36, § 3.º, por meio de decreto, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade ■ Nessa fase, está dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa (controle político)
Fase 3 — “Intervenção Efetiva”		

Fase 3 — “Intervenção Efetiva”		
DECRETO DO EXECUTIVO E CONTROLE POLÍTICO	■ Caso a medida de mera suspensão não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, aí, sim, o Presidente da República decretará a efetiva intervenção no Estado ou no DF, executando-a com a nomeação de interventor, se for o caso, e afastando as autoridades responsáveis de seus cargos (art. 84, X, da CF/88) ■ Nesse caso de intervenção efetiva, haverá controle político pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas a contar do decreto interventivo. Se o Congresso Nacional não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária ■ Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal	■ Caso a medida de mera suspensão não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, aí, sim, o Governador do Estado decretará a efetiva intervenção no Município, executando-a com a nomeação de interventor, se for o caso, e afastando as autoridades responsáveis de seus cargos (art. 84, X, da CF/88) ■ Nesse caso de intervenção efetiva, haverá controle político pela Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas a contar do decreto interventivo. Se a Assembleia Legislativa não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária ■ Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal

■ 6.8. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS ESTADOS-MEMBROS

■ 6.8.1. Regras gerais

Nos termos do art. 125, § 2.º, da CF/88, cabe aos Estados a instituição de **representação de inconstitucionalidade** de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Nesse sentido, o constituinte consagrou o controle abstrato de constitucionalidade estadual, fixando regras claras:

somente leis ou atos normativos **estaduais** ou **municipais** poderão ser objeto de controle;

apesar de não fixar os legitimados, **vedou** a atribuição da legitimação para agir a um único órgão;

o órgão competente para o julgamento da ação pela via principal será, exclusivamente, o **TJ local**.

Pelo princípio da simetria, muito embora o art. 125, § 2.º, tenha fixado somente a possibilidade de instituição de **representação de inconstitucionalidade** (que corresponderia à ADI), parece-nos perfeitamente possível que, desde que respeitadas as regras da CF/88, se implementem os demais meios de controle, [243](#) especialmente a ADO para combater a inércia do Legislativo estadual.

■ 6.8.2. Objeto

A teor do art. 125, § 2.º, da CF/88, o controle abstrato estadual terá por objeto **exclusivamente** leis ou atos normativos **estaduais** ou **municipais**.

Pode-se afirmar, assim, que o TJ local nunca julgará, em controle concentrado e abstrato, lei federal. Ou, em outras palavras, as leis federais só poderão ser objeto de controle abstrato perante o STF. Ou, ainda, o STF não julgará em ADI lei municipal perante a CF (só por meio de ADPF, como visto, ou, excepcionalmente, nas hipóteses de RE de normas de reprodução obrigatória, conforme desenvolvido no *item 6.8.6*).

■ 6.8.3. Competência

Somente o **TJ local** será o órgão competente para, exercendo competência originária, julgar o controle de constitucionalidade abstrato estadual (art. 125, § 2.º).

■ 6.8.4. Legitimados

A regra constitucional não especificou os legitimados. Apenas proibiu a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Assim, cabe às Constituições Estaduais a delimitação da regra, e, nesse sentido, como se trata de manifestação do *poder constituinte derivado decorrente*, deve-se respeitar, pela **simetria**, o art. 103 da CF/88, consoante o quadro abaixo:

ART. 103 — CF/88 — LEGITIMADOS PARA O CONTROLE CONCENTRADO PERANTE O STF	ART. 125, § 2.º — CF/88 — LEGITIMADOS PARA O CONTROLE CONCENTRADO PERANTE O TJ LOCAL — “PRINCÍPIO DA SIMETRIA”	ART. 125, § 2.º — CF/88 — LEGITIMADOS PARA O CONTROLE CONCENTRADO PERANTE O TJ LOCAL — “PRINCÍPIO DA SIMETRIA” — ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO A LEIS OU ATOS MUNICIPAIS
■ Presidente da República	■ Governador de Estado	■ Prefeito
■ Mesa do Senado Federal	■ Mesa de Assembleia	■ Mesa de Câmara

■ Mesa da Câmara dos Deputados	Legislativa	Municipal
■ Procurador-Geral da República	■ Procurador-Geral de Justiça	
■ Conselho Federal da OAB	■ Conselho Seccional da OAB	
■ Partido político com representação no Congresso Nacional	■ Partido político com representação na Assembleia Legislativa	■ Partido político com representação na Câmara do Município
■ Confederação sindical ■ Entidade de classe de âmbito nacional	■ Federação sindical ■ Entidade de classe de âmbito estadual	

A pergunta que surge é se poderia a Constituição Estadual ampliar para **Deputados Estaduais, Procurador-Geral do Estado** ou do **Município, Defensor Público-Geral do Estado**, ou ainda por **iniciativa popular** (ação popular — *Popularklage*), legitimados que não guardam simetria com o art. 103 (que não fixou legitimação para Deputado Federal ou Senador, ou para o AGU ou Procurador da Fazenda, ou Defensor Público Geral da União etc.).

Entendemos que **sim**, até porque tal previsão prestigiaria a intenção do constituinte de 1988, que foi no sentido de ampliar o rol de legitimados para a propositura de ADI.

O STF já se manifestou em relação aos Deputados Estaduais: “Legitimação ativa de Deputado Estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado, à vista do art. 125, § 2.º, da

Constituição Federal. Precedente: **ADI 558-9-MC**, Pertence, j. 16.08.91, *DJ* 26.03.93” (**RE 261.677**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.04.2006, *DJ* de 15.09.2006).

Outrossim, no precedente citado (ADI 558-9-MC), em julgamento de medida cautelar (pendente a apreciação do mérito), o STF entendeu como **constitucional** o art. 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com o seguinte teor: “Art. 162. A representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Constituição, pode ser proposta pelo **Governador do Estado**, pela **Mesa**, por **Comissão Permanente** ou pelos **membros da Assembleia Legislativa**, pelo **Procurador-Geral da Justiça**, pelo **Procurador-Geral do Estado**, pelo **Procurador-Geral da Defensoria Pública**, **Defensor Público Geral do Estado**, por **Prefeito Municipal**, por **Mesa de Câmara de Vereadores**, pelo **Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil**, por **partido político com representação na Assembleia Legislativa** ou em **Câmara de Vereadores**, e por **federação sindical** ou **entidade de classe de âmbito estadual**”.

Assim, ampliar, em âmbito estadual, os parâmetros estabelecidos pelo art. 103, CF/88, parece perfeitamente possível. E restringir, aquém da simetria, caracterizaria afronta à Constituição?

Cumprindo a literalidade da regra do art. 125, § 2.º, deverá ser observada a proibição de se estabelecer a legitimação para agir a um único órgão. Contudo, entendemos **conveniente** que se faça, ao menos, mas podendo ser ampliada, uma **simetria estrita**, apesar de o tema ainda não ter sido decidido pelo STF no caso da previsão bastante ampliada prevista no mencionado art. 162 da CE/RJ (ADI 558-9).

■ 6.8.5. Parâmetro de controle

■ 6.8.5.1. Regras gerais

CONTROLE CONCENTRADO POR MEIO DE ADI GENÉRICA			
STF (ADI)		TJ (ADI)	
objeto: lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital de natureza estadual		objeto: lei ou ato normativo estadual ou municipal e, no âmbito do DF, lei ou ato normativo distrital de natureza estadual ou municipal	
Lei Municipal ou Lei Distrital de natureza Municipal	Regra: o STF não é intérprete originário de lei municipal ou distrital de natureza municipal por meio de ADI	Lei Federal	Regra: o TJ não é intérprete originário de lei federal por meio de ADI estadual ou distrital
parâmetro: CF		parâmetro: CE ou, perante o DF, Lei Orgânica do DF	
CE ou Lei Orgânica do DF	Regra: a CE ou a Lei Orgânica do DF não podem ser parâmetro de controle para o ajuizamento de ADI originária, já que o STF é o intérprete final da CF	CF	Regra: a CF não pode ser parâmetro de controle para o ajuizamento de ADI originária, já que o TJ é o intérprete final da CE ou, no âmbito distrital, da Lei Orgânica do DF

Conforme estudado e sempre tendo em vista a regra fixada no art. 125, § 2.º, o controle abstrato estadual por meio de ADI só poderá apreciar lei ou ato normativo **estadual** ou **municipal** que forem confrontados perante a **Constituição Estadual**, ou lei ou ato normativo distrital perante a Lei Orgânica do DF.

O **TJ**, assim, só realiza controle abstrato tendo como parâmetro a **CE**, não

podendo ter como parâmetro (controle concentrado e abstrato) a CF e, no caso do DF, tendo por parâmetro a Lei Orgânica do DF. [244](#)

Por sua vez, o **STF** só realiza controle concentrado e abstrato, por meio da ADI genérica, tendo como parâmetro a **CF**, não podendo ter como paradigma de confronto a CE ou a Lei Orgânica do DF, já que o STF é o intérprete final da CF.

Em relação ao objeto, o **TJ** só apreciará lei **municipal** ou **estadual** (aplicando-se, naturalmente, a regra para o DF, que acumula tanto a competência municipal como a estadual), enquanto o **STF**, apenas lei **federal** ou **estadual** (ou distrital de caráter estadual).

O TJ, então, **não** poderá realizar controle concentrado de lei federal, por meio de ADI genérica, seja em face da CE, seja em face da CF.

Em igual sentido, o STF **não** poderá analisar, por meio da ADI genérica, lei municipal em face da CE (ou lei distrital, perante a Lei Orgânica do DF), mas apenas e excepcionalmente a lei municipal (ou distrital de natureza municipal) perante a CF, mas pela **ADPF**.

Vejam que estamos nos referindo ao controle concentrado e em abstrato por meio da ADI genérica. Isso porque, em se tratando de controle difuso, seria perfeitamente possível que o TJ (art. 97 — cláusula de reserva de plenário), pelo Pleno ou Órgão Especial, de maneira incidental, apreciasse a constitucionalidade de lei federal perante a CF. Mas, percebam, somente no controle difuso.

■ **6.8.5.2. A parametricidade das cláusulas constitucionais estaduais, de caráter remissivo, para fins de controle concentrado, no âmbito do TJ local**

Para a definição de competência no julgamento, já vimos, duas questões deverão ser observadas, quais sejam, o objeto da ação e o parâmetro, pauta de referência ou paradigma de confronto.

Isso quer dizer que uma lei ou ato normativo é inconstitucional por violar um parâmetro, que pode ser tanto a CF como a CE ou a Lei Orgânica do DF.

Pois bem, o STF chegou a analisar se o controle em âmbito estadual poderia ter por paradigma de confronto regra contida na Constituição de determinado Estado, que simplesmente remete e reproduz regra idêntica contida na CF.

Celso de Mello, com precisão, admite a possibilidade de “... se **invocar**, como **referência paradigmática**, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, **cláusula de caráter remissivo**, que, inscrita na Constituição Estadual, **remete**, diretamente, às **regras normativas constantes da própria Constituição Federal**, assim incorporando-as, formalmente, mediante referida **técnica de remissão**, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro”.

E completa: “com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o ‘corpus’ constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como **parâmetro** de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2.º, da Constituição da República, a **própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo**” (Rcl 10.500, j. 18.10.2010, cf. *Inf. 606/STF*). [245](#)

■ 6.8.5.3. “*Simultaneus processus*”

E as **leis estaduais**?

As leis **estaduais**, em se tratando de controle concentrado pela via em abstrato, sofrem **dupla fiscalização**, tanto por meio de ADI no TJ e tendo como parâmetro a CE como perante o STF e tendo como parâmetro a CF.

Isso significa que a mesma lei estadual poderá ser objeto de controle concentrado no TJ e no STF. Se isso acontecer, estaremos diante do fenômeno da **simultaneidade de ações diretas de inconstitucionalidade**, também denominado *simultaneus processus*.

Nessa situação, em sendo o mesmo objeto (vale dizer, a mesma lei estadual), assim como o parâmetro estadual de confronto, norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição Federal, o controle estadual deverá ficar **suspenso** (em

razão da causa de **suspensão prejudicial** do referido processo), aguardando o resultado do controle federal, já que o STF é o intérprete máximo da Constituição. Confira:

“EMENTA: Ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade tanto perante o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘a’) quanto perante Tribunal de Justiça Local (CF, art. 125, § 2.º). Processos de fiscalização concentrada nos quais se impugna o **mesmo diploma normativo** emanado de Estado-membro, não obstante contestado, perante o Tribunal de Justiça, em face de princípios, que, inscritos na carta política local, revelam-se impregnados de predominante coeficiente de federalidade (RTJ 147/404 — RTJ 152/371-373). Ocorrência de **‘simultaneus processus’**. Hipótese de **suspensão prejudicial** do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Necessidade de se aguardar, em tal caso, a conclusão, pelo Supremo Tribunal Federal, do julgamento da Ação Direta. Doutrina. Precedentes (STF)”.

Nesse sentido, continua o Min. Celso de Mello, “a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, perante o Supremo Tribunal Federal, em que se postule a invalidação de legislação editada por Estado-membro, questionada em face da Constituição da República (CF, art. 102, I, *a*), qualifica-se como causa de suspensão prejudicial do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que, promovido perante o Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, § 2.º), tenha, por objeto de impugnação, os **mesmos atos normativos emanados do Estado-membro**, contestados, porém, em face da Constituição Estadual (...). Tal entendimento, no entanto, há de ser observado sempre que tal impugnação — deduzida perante a Corte Judiciária local — invocar, como **parâmetro de controle, princípios inscritos na Carta Política local impregnados de predominante coeficiente de federalidade, tal como ocorre com os postulados de reprodução necessária constantes da própria Constituição da República** (RTJ 147/404 — RTJ 152/371-373, v.g.)” (ADI 4.138, j. 11.12.2009, cf. Inf. 573/STF).

Verificado o fenômeno do *simultaneus processus*, as seguintes hipóteses poderão surgir a partir da decisão a ser proferida pelo STF:

■ **STF declara inconstitucional a lei estadual perante a CF** — a ADI estadual perderá o seu objeto, não mais produzindo a lei efeitos no referido Estado;²⁴⁶

STF declara constitucional a lei estadual perante a CF — o TJ poderá prosseguir o julgamento da ADI da lei estadual diante da CE, pois, perante a Constituição Estadual, a referida lei poderá ser incompatível (mas, naturalmente, **desde que seja por fundamento diverso**).

Vamos imaginar agora que a ação seja proposta perante o TJ estadual e que este julgue a ação que transita em julgado. Poderá no futuro a mesma lei ser examinada em controle abstrato perante o STF e tendo como parâmetro a CF? Duas são as hipóteses:

■ **TJ declara previamente a lei estadual constitucional** — naturalmente, para essa hipótese, não se tratará de simultaneidade. Assim, em sendo no futuro ajuizada a ADI perante o STF, tendo por objeto a mesma lei estadual, o STF poderá reconhecê-la como **inconstitucional** diante da CF. Como o STF é o intérprete máximo da constitucionalidade das leis e o responsável por apontar a *força normativa* da Constituição, a nova decisão do STF prevalecerá inclusive sobre a coisa julgada estadual;

■ **TJ declara previamente a lei estadual inconstitucional** — entendemos que não haveria mais sentido falar em controle perante o STF, já que a lei estadual foi retirada do ordenamento jurídico.

■ 6.8.6. A utilização do recurso extraordinário no controle concentrado e em abstrato estadual

De modo geral, da decisão do TJ local em controle abstrato (ADI) de lei **estadual** ou **municipal** diante da CE **não** cabe recurso para o STF, já que o STF é o intérprete máximo de lei (federal, estadual ou distrital de natureza estadual) perante a CF, e não perante a CE.

Excepcionalmente, contudo, pode surgir situação em que o parâmetro da CE nada mais seja que uma **norma de observância obrigatória** ou **compulsória pelos Estados-Membros** (norma de **reprodução obrigatória**).

Nesse caso, se a lei **estadual**, ou mesmo a **municipal**, viola a CE, no fundo, pode ser que ela esteja, também, violando a CF. Como o TJ não tem essa atribuição de análise, buscando evitar a situação de o TJ usurpar competência do STF (o intérprete máximo da Constituição), abre-se a possibilidade de se interpor **recurso extraordinário** contra o acórdão do TJ em controle abstrato estadual para que o STF diga, então, qual a interpretação da lei **estadual** ou **municipal** perante a **CF**.

Trata-se, pois, de utilização de recurso típico do controle difuso (pela via incidental) no controle concentrado e em abstrato estadual.

O recurso extraordinário será um simples mecanismo de se levar ao STF a análise da matéria. Assim, a decisão do STF nesse específico recurso extraordinário produzirá os mesmos efeitos da ADI, ou seja, por regra, *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, podendo o STF, naturalmente, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, modular os efeitos da decisão. Portanto, não se aplicará a regra do art. 52, X, não tendo o Senado Federal qualquer participação.

Desse modo, **e tomem cuidado com essa constatação**, surgirá a possibilidade de o STF analisar a constitucionalidade de lei municipal perante a CF e com efeitos *erga omnes*, se na análise inicial do controle abstrato estadual a lei municipal foi confrontada em relação à norma da CE de reprodução obrigatória e compulsória da CF.

Nesse sentido, confirmam os julgados abaixo:

“Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante **Tribunal de Justiça** na qual se impugna **Lei municipal** sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que **reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados**. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de **recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance**

desta” (Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, j. 11.06.1992, DJ de 21.05.1993).

“... o Tribunal, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Min. Moreira Alves, entendeu que a decisão tomada em **recurso extraordinário** interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça em representação de inconstitucionalidade de **lei municipal frente à Constituição Estadual** (CF, art. 125, § 2.º) tem eficácia *erga omnes*, por se tratar de controle concentrado **ainda que a via do recurso extraordinário seja própria do controle difuso**, eficácia essa que se estende a todo o território nacional” (RE 187.142-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.08.1998, Inf. 118/STF).

Dentre outros exemplos, destacamos, ainda, o **RE 199.281** e a **ADI 1.268**.

■ 6.9. QUADRO COMPARATIVO DO SISTEMA JURISDICIONAL MISTO DE CONTROLE POSTERIOR OU REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

	OBJETO	COMPETÊNCIA	LEGITIMAÇÃO ATIVA	CAUTELA
Controle difuso — atos normativos	■ Qualquer lei ou ato de indiscutível caráter normativo, contrário à Constituição (via de exceção ou defesa — declaração de	■ Qualquer juízo ou Tribunal	■ Qualquer pessoa física ou jurídica, no caso concreto	■ Possuindo-se seguindo-se regras processuais

	inconstitucionalidade <i>incidenter tantum</i>)			
Controle difuso — omissões — mandado de injunção individual ou coletivo (vide capítulo sobre remédios constitucionais)	■ Falta de medida regulamentadora de artigo da Constituição de eficácia limitada, prescrevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania	■ Arts. 102, I, “q”, 102, II, “a”, 105, I, “h”, 121, § 4.º, V, e 125, § 1.º (qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de organização judiciária)	■ Qualquer pessoa, física ou jurídica, no caso concreto	■ Impossibilidade. Contudo, tendo em vista novas tendências, pode-se pensar na modificação do entendimento

ADI genérica (controle concentrado no STF)	■ Lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital (natureza estadual), contestados em face da CF/88 (via de ação, controle abstrato, em tese)	■ STF — competência originária	■ Arts. 103 da CF/88 e 2.º da Lei n. 9.868/99	■ Possível art. 102, I, “<i>l</i>”
	■ Evitar ou reparar lesão a preceito			

Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)	lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público e quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, distrital, incluídos os anteriores à Constituição	■ STF — competência originária	■ Arts. 103 da CF/88 e 2.º da Lei n. 9.882/99 (os mesmos da ADI)	■ Possível 5.º da Le 9.882/99)

ADI omissão (ADO)	por ■ Falta de medida regulamentadora de artigo da Constituição de eficácia limitada	■ STF — competência originária	■ Arts. 103 da CF/88 e 12-A da Lei n. 9.868/99	■ Possível 12-F da Lei 9.868/99)
------------------------------	---	--	---	---

Representação Interventiva (ADI Interventiva)	■ Lei ou ato normativo, ato administrativo, ato concreto, ou omissões, estaduais ou distritais que violam princípios sensíveis da CF/88 ■ A hipótese de recusa, por parte de Estado-Membro ou do DF, à execução de lei federal vai ser estudada no <i>item 7.12.1</i>	■ STF — competência originária	■ Procurador-Geral da República — art. 36, III, da CF/88	■ Possibilic (art. 5.º da n. 12.562/20
---	---	--	---	---

ADC	Lei ou ato normativo federal	STF — competência originária	Art. 103 da CF/88 (modificado pela EC n. 45/2004)	Possibilic (jurisprudên do STF — , 4)

■ 6.10. QUESTÕES

■ 6.10.1. Conceitos gerais

1. (OAB/113.º) O Presidente da República expede Decreto com o fim de regulamentar determinada lei federal. No entanto, o Decreto acaba por criar determinada obrigação não prevista na lei regulamentada. Em tal hipótese, o Congresso Nacional:

- poderia revogar todo o Decreto, por meio de Resolução;
- poderia revogar a parte do Decreto que criou a obrigação não prevista na lei, por meio de Resolução;

Decreto Legislativo;

- d) nada poderia fazer em relação ao Decreto, em respeito ao princípio da separação de poderes.

2. (OAB/107.º) Quando da promulgação de uma nova Constituição, diz-se que a legislação ordinária compatível perde o suporte de validade da constituição antiga, mas continua válida pela teoria:

- a) da repristinação;
- b) da desconstitucionalização;
- c) da recepção;
- d) do poder constituinte subordinado.

3. (OAB/113.º) Quando se diz caber a todos os componentes do Poder Judiciário o exercício do controle da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país, está se falando em:

- a) controle constitucional difuso, por via de ação;
- b) jurisdição constitucional concentrada, por via de exceção;
- c) jurisdição constitucional difusa, por via de exceção;
- d) controle constitucional concentrado, por via de ação.

4. (OAB/109.º) Parecer normativo da Consultoria-Geral da República, aprovado pelo Presidente da República:

- a) pode ser objeto de impugnação mediante ação direta de inconstitucionalidade;
- b) não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porque tem natureza administrativa;
- c) só pode ser objeto de controle de legalidade, não de constitucionalidade;
- d) só pode ser impugnado em controle difuso de constitucionalidade.

5. (OAB/112.º) A Ação Declaratória de Constitucionalidade, proposta pela Mesa do Senado e que tenha por objeto Decreto do Presidente da República regulamentando lei federal, a priori:

- a) deve ser julgada procedente, pois não apresenta nenhum vício de ordem processual;
- b) deve ser julgada procedente, pois, mesmo diante de eventual afronta à Constituição Federal, o julgamento improcedente implicaria declaração de inconstitucionalidade do ato, o que não é possível nessa espécie de ação que tem por finalidade a declaração

da constitucionalidade da norma;

- c) não deve ser conhecida, pois o Presidente do Senado, e não a Mesa, é legitimado para propor a ação;
- d) não deve ser conhecida, porquanto se está diante de questão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade.

6. (PROC/MP/MG/2007) Considere as seguintes ações:

- I. Ação de competência do Supremo Tribunal Federal destinada a obter a decretação de inconstitucionalidade, em tese, de lei federal ou estadual, sem outro objetivo, senão o de expurgar da ordem jurídica a incompatibilidade vertical. Visa, exclusivamente, a defesa do princípio da supremacia constitucional.
- II. Ação, que pode ser federal, por proposta exclusiva do Procurador-Geral da República, e de competência do Supremo Tribunal Federal, destinada a promover a intervenção federal em Estado da federação.
- III. Ação cujo pressuposto é a controvérsia a respeito da constitucionalidade da lei, tendo como finalidade imediata a rápida solução dessas pendências, e como objeto a verificação da constitucionalidade de um ato normativo federal impugnado em processos concretos.

Essas situações dizem respeito, respectivamente, às ações

- a) direta de inconstitucionalidade genérica, direta de inconstitucionalidade interventiva, e direta de inconstitucionalidade específica;
- b) direta de inconstitucionalidade não interventiva, direta de inconstitucionalidade específica, e direta de inconstitucionalidade genérica;
- c) declaratória de constitucionalidade, direta de inconstitucionalidade interventiva, e direta de inconstitucionalidade genérica;
- d) declaratória de constitucionalidade, direta de inconstitucionalidade genérica, e direta de inconstitucionalidade não interventiva;
- e) direta de inconstitucionalidade genérica, direta de inconstitucionalidade interventiva, e declaratória de constitucionalidade.

7. (CESPE/UnB — STF/Analista Judiciário — Área: Judiciária/2008) O presidente da República promulgou simultaneamente três leis. A Lei X, de autoria parlamentar, tinha por objeto a aprovação do plano de cargos e salários dos servidores da justiça federal de primeira e segunda instâncias, com vistas a suprir necessidade nos tribunais regionais federais. A Lei Y, que é a lei orçamentária anual, para o

nos tribunais regionais federais. A Lei Y, que é a lei orçamentária anual, para o exercício de 2008. E a Lei W, de iniciativa do presidente da República, que cria uma rádio pública. Ocorre que a Lei W foi aprovada, pela Câmara dos Deputados, com a votação favorável de 200 deputados, sendo que, desses, pelo menos, 80 teriam recebido vantagens econômicas para votar pela aprovação dessa lei. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, a respeito do controle de constitucionalidade e do processo legislativo.

A Lei Y possui, de acordo com a doutrina, o chamado vício de decoro parlamentar, o que geraria a sua inconstitucionalidade.

8. (AGU — CESPE/2010) Julgue o item subsequente, relativo ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade no Brasil.

De acordo com entendimento do STF, o controle jurisdicional prévio ou preventivo de constitucionalidade sobre projeto de lei ainda em trâmite somente pode ocorrer de modo incidental, na via de exceção ou defesa.

9. (Analista Processual MPU — CESPE/2010) O Estado brasileiro, como estado democrático de direito, apresenta, no seu texto constitucional, os parâmetros para o exercício da soberania popular, a partir de princípios e normas basilares, submetidos a constante controle. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir.

Verifica-se a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional contém algum vício em sua forma, independentemente do conteúdo.

10. (Delegado de Polícia — ACADEPOL/MG/2011) O “bloco de constitucionalidade” se constitui a partir de:

- a) princípios, normas escritas e não escritas, fundamentos relativos à organização do Estado, direitos sociais e econômicos, direitos humanos reconhecidos em tratados e convenções internacionais dos quais o país seja signatário.
- b) normas escritas, emendas constitucionais de lastro formal, direitos fundamentais consagrados pela Constituição, de reconhecimento e aplicação internos.
- c) princípios não escritos, unidade, solidez, valoração de normas constitucionais que podem ser desmembradas para melhor efetivação dos direitos consagrados.
- d) conteúdo específico das normas constitucionais e infraconstitucionais, estabilidade, dinamicidade, dirigismo, garantismo, além de todas as normas constitucionais de caráter

11. (Defensor Público/AM — Instituto Cidades/2011) Qual dos instrumentos abaixo jamais poderá ser utilizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, federal ou estadual:

- a) recurso extraordinário;
- b) embargos de declaração;
- c) ação rescisória;
- d) intervenção de *amicus curiae*;
- e) audiência pública.

12. (Promotor de Justiça/MS — 2011) Havendo evidente controvérsia constitucional acerca de importante dispositivo de lei estadual anterior à Constituição Federal de 1988, o Governador do Estado é legitimado a ingressar no Supremo Tribunal Federal com:

- a) mandado de segurança;
- b) ação direta de inconstitucionalidade;
- c) ação declaratória de constitucionalidade;
- d) mandado de injunção;
- e) arguição de descumprimento de preceito fundamental.

13. (25.º Concurso MPF/PGR/2011) Leia os enunciados abaixo. Considerando a jurisprudência atual do STF, quais as respostas corretas?

- I. O pressuposto da subsidiariedade, na ADPF de natureza incidental, leva em consideração a existência de outro instrumento no controle abstrato de normas apto a sanar a lesão ao preceito fundamental não apenas para as partes do processo originário, mas para todos os que se encontrarem em situação similar.
 - II. O princípio da reserva de plenário não se aplica ao próprio STF, no julgamento de recursos extraordinários.
 - III. Não cabe o controle abstrato de constitucionalidade de decreto expedido pelo Presidente da República.
 - IV. É incabível a propositura de ADI contra lei formal, dotada de efeitos concretos.
- a) I e II.
 - b) I, II e III.
 - c) I, II, III e IV.
 - d) III e IV.

14. (Advogado — AGU — CESPE/UnB-2012) Com relação à ADI e à ADO, julgue o item subsecutivo:

Considere a seguinte situação hipotética. Foi ajuizada ADI no STF contra lei estadual por contrariedade a dispositivo expresso na CF. Porém, antes do julgamento da ação, o parâmetro de controle foi alterado, de modo a tornar a norma impugnada consentânea com o dispositivo constitucional. Nessa situação hipotética, admite-se, de acordo com recente jurisprudência do STF, a denominada constitucionalidade superveniente, devendo, portanto, ser afastada a aplicação do princípio da contemporaneidade e julgada improcedente a ação.

■ **6.10.2. Legitimidade**

1. (OAB/104.º) Um dos grupos ou pessoas abaixo nomeados certamente não é legitimado para intentar ação de inconstitucionalidade:

- a) o Presidente da República;
- b) a Mesa da Assembleia Legislativa;
- c) o partido político, desde que possua representação no Congresso Nacional;
- d) entidade de classe de âmbito municipal ou estadual.

2. (Magistratura/173.º) Assinale a correta. A ação declaratória de constitucionalidade pode ser proposta:

- a) pelo Governador do Estado;
- b) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- c) pelo Procurador-Geral da República;
- d) pela Mesa da Assembleia Legislativa.

3. (OAB/111.º) Havendo afronta aos direitos da pessoa humana pelo Governador, o respectivo Estado-membro poderá sofrer intervenção federal mediante:

- a) Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, proposta pelo Procurador-Geral do Estado;
- b) requisição do Tribunal de Justiça;
- c) solicitação da Assembleia Legislativa;
- d) Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, proposta pelo Procurador-Geral da República.

- c) solicitação da Assembleia Legislativa;
- d) Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, proposta pelo Procurador-Geral da República.

4. (Defensoria Pública da União — CESPE/UnB — 2010) No que se refere ao controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte:

Considere que o art. Y da Constituição do Estado X estabeleça a legitimidade de deputado estadual para propor ação de inconstitucionalidade de lei municipal ou estadual em face da Constituição estadual. Nesse caso, conforme entendimento do STF, o referido art. Y poderá ser considerado constitucional.

5. (Analista Judiciário/TJ-ES — Direito — CESPE/UnB/2011) Acerca do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pode ser proposta pelos mesmos legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade genérica e da ação declaratória de constitucionalidade.

6. (Auditor Público Externo — TCE/MT — FMP-RS/2011) É parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal conforme a Constituição do Estado do Mato Grosso:

- a) a mesa do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.
- b) o Ministério Público do Estado do Mato Grosso.
- c) o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.
- d) partidos políticos com representação no Estado do Mato Grosso.
- e) o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

7. (Analista — Advocacia — CESPE/UnB — EBC-1/2011) A aferição da legitimidade do partido político para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade deve ser feita no momento da propositura da ação, sendo irrelevante a ulterior perda de representação no Congresso Nacional.

8. (Delegado de Polícia — FGV — PC/MA/2012) Determinada associação de âmbito nacional, que congrega trabalhadores da indústria automotiva, montadoras instaladas no país e revendedores de veículos e bens correlatos, ajuíza uma ação direta de inconstitucionalidade contra lei federal que determinou a majoração do

um dos legitimados à propositura da ação.

- b) A associação de âmbito nacional está dispensada de demonstrar o requisito da pertinência temática para o ajuizamento da ação.
- c) O caráter nacional da associação é verificado pela declaração constante dos seus atos constitutivos.
- d) A associação em tela não preenche o requisito da homogeneidade para qualificar-se como legitimado à propositura da ação.
- e) Não se admite a legitimidade de associações constituídas por pessoas jurídicas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

■ 6.10.3. Procedimento

1. (OAB/104.º) Assinale a alternativa correta:

- a) ao Presidente da República compete suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF;
- b) ao Presidente da Câmara dos Deputados compete suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF;
- c) ao Conselho da República compete suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF;
- d) ao Senado Federal compete suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF.

2. (OAB/110.º) Ação Declaratória de Constitucionalidade visando declarar a constitucionalidade de determinada Emenda à Constituição Federal não poderá ser proposta pelo Procurador-Geral da República no dia seguinte à promulgação da referida lei porque:

- a) Emenda à Constituição Federal não pode ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade, uma vez que é produzida pelo Poder Constituinte Reformador;
- b) o Procurador-Geral da República não é parte legítima para propor Ação Declaratória de Constitucionalidade, atuando no processo, apenas, como “fiscal da lei”;
- c) não existiria controvérsia judicial, requisito indispensável à propositura de Ação Declaratória de Constitucionalidade;
- d) somente atos infraconstitucionais podem ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade, deles excluída, portanto, a Emenda à Constituição Federal.

3. (MP/81.º/2.ª Prova) Deve ser apontada a alternativa em que se inclui equívoco. No procedimento da ação direta de inconstitucionalidade mostra-se admissível:

- a) a requisição de informações adicionais pelo relator;
- b) a designação de perito ou de comissão de peritos para emissão de parecer sobre matéria ou situação fática que necessite de esclarecimento;
- c) a realização de audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria não esclarecida;
- d) a intervenção de terceiros;
- e) a desistência da ação.

4. (OAB/119.º) Lei municipal que concede subvenção a determinada seita religiosa deve ser considerada:

- a) inconstitucional, podendo ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal;
- b) inconstitucional, podendo ser impugnada por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal, desde que observado o princípio da subsidiariedade;
- c) constitucional, podendo ser assim declarada, no caso de divergência jurisprudencial, em ação declaratória de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal;
- d) constitucional, pois a Constituição Federal autoriza a concessão de subsídios a qualquer espécie de culto religioso.

5. (X Concurso — 1.ª Prova Escrita/Juiz Federal TRF2) Admite-se a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quando este terceiro interveio no processo como “amicus curiae”?

6. (MP/SP/2006) Relativamente à Cláusula de Reserva de Plenário, assinale a alternativa correta.

- a) Toda demanda que suscite questão constitucional deve ser apreciada, originalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob pena de nulidade de julgamento.
- b) Toda demanda que suscite questão constitucional deve ser apreciada, originalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, que, somente pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

- b) Toda demanda que suscite questão constitucional deve ser apreciada, originalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, que, somente pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- c) Compete ao Supremo Tribunal Federal, privativamente, tanto em suas ações originárias, quanto no exercício de sua competência recursal, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo voto da maioria de seus ministros.
- d) Somente pelo voto de 2/3 de seus membros poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, sob pena de nulidade do julgamento.
- e) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

7. (Procurador da Assembleia Legislativa/ES — CESPE/UnB/2011) No que diz respeito ao controle de constitucionalidade no sistema brasileiro, assinale a opção correta:

- a) No controle difuso concreto, o magistrado de primeira instância, bem como as turmas ou as câmaras dos tribunais locais, pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma incidentalmente em um caso concreto, ainda que não haja pronunciamento dos tribunais ou do STF sobre a questão.
- b) O STF admite a modulação de efeitos da decisão que declare a inconstitucionalidade no controle difuso concreto e da decisão que exerça juízo de não recepção de normas anteriores à CF.
- c) Segundo entendimento do STF, a cláusula de reserva de plenário não se aplica às turmas recursais dos juizados especiais.
- d) No denominado controle abstrato de constitucionalidade, o STF não pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma ou de ato normativo que não tenha sido objeto do pedido.
- e) No que se refere ao momento da realização do controle de constitucionalidade, é admitido o controle judicial preventivo, realizado pelo STF no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.

8. (Delegado Federal — CESPE/UnB/2013) De acordo com entendimento do STF, no controle difuso de constitucionalidade, os tribunais não podem aplicar a denominada interpretação conforme a CF sem a observância da cláusula de

correta:

- a) Compete aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, reconhecida a legitimação para agir aos mesmos órgãos e entidades legitimados a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
- b) A decisão do Tribunal de Justiça que declara a inconstitucionalidade de lei local em face da Constituição Estadual é irrecurível, ressalvada a oposição de embargos declaratórios.
- c) Não ofende a Constituição da República norma de Constituição Estadual que atribui legitimidade para a propositura de representação de inconstitucionalidade aos Deputados Estaduais e ao Procurador-Geral do Estado.
- d) Não é possível o controle de constitucionalidade no plano estadual, no modo concentrado, se a norma constitucional estadual tomada como parâmetro reproduzir idêntico conteúdo de norma constitucional federal.

10. (Magistratura/TJ-PE — FCC/2011) Considerada a disciplina constitucional e a respectiva regulamentação legal da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é INCORRETO afirmar que:

- a) pode ser proposta pelos legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade.
- b) não admite desistência.
- c) não admite medida cautelar.
- d) cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.
- e) em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo STF, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.

11. (Analista Judiciário — TRE-PA — FGV/2011) O controle concentrado de constitucionalidade pode ser exercido por meio de diversos instrumentos elencados na Constituição. Nesse sentido, é correto afirmar que (questão adaptada pelo autor, na medida em que a prova é de múltipla escolha, com 5 alternativas):

O Advogado-Geral da União funciona como uma espécie de curador da presunção de constitucionalidade dos atos emanados do Poder Público; entretanto, ele não está

obrigado a defender tese jurídica se sobre ela o STF já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade.

■ 6.10.4. Efeitos da decisão

1. (OAB/111.º) A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade que declarar a inconstitucionalidade de tratado internacional, devidamente ratificado e promulgado pelo Estado brasileiro:

- a) será nula, uma vez que tratados internacionais não podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade;
- b) produzirá apenas efeitos *ex tunc*, uma vez que, pelo princípio da soberania, os Estados estrangeiros não poderão ser vinculados ao cumprimento de tal decisão;
- c) dependerá de posterior manifestação do Senado Federal para suspender a execução do tratado na ordem jurídica interna;
- d) produzirá efeitos *erga omnes* e vinculante, resultando na inaplicação do tratado na ordem jurídica interna.

2. (OAB/112.º) A declaração de inconstitucionalidade de ato normativo que revoga outro ato normativo tem como consequência lógica:

- a) o restabelecimento do ato normativo anterior;
- b) a repristinação do ato normativo anterior;
- c) a perda de eficácia de ambos os atos;
- d) a impossibilidade de restabelecer o ato normativo anterior.

3. (Magistratura/AL/2007) Sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é INCORRETO afirmar que:

- a) pode ter por objeto lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, quando relevante o fundamento da controvérsia constitucional a seu respeito;
- b) estão legitimados para sua propositura, dentre outros, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República e entidade de classe de âmbito nacional;
- c) possui caráter subsidiário, uma vez que não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade a preceito fundamental resultante de ato do Poder

Distrito Federal, o Procurador-Geral da República e entidade de classe de âmbito nacional;

- c) possui caráter subsidiário, uma vez que não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público;
- d) caberá agravo da decisão de indeferimento da petição inicial, no prazo de cinco dias, mas será irrecurável a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido na arguição;
- e) poderá ser deferida medida liminar para que juízes e Tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais quaisquer, inclusive se decorrentes de coisa julgada.

4. (PFN — ESAF — 2005-6) De modo geral, a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade de lei em ação direta de inconstitucionalidade começa a produzir todos os seus efeitos:

- a) desde o trânsito em julgado da decisão.
- b) desde a publicação do acórdão, com a respectiva ementa, no Diário de Justiça.
- c) desde a data da publicação da ata da sessão de julgamento.
- d) desde o dia mesmo do julgamento da ação.
- e) no primeiro dia útil seguinte ao do julgamento da ação.

5. (Juiz — TRF 5.^a Reg. — 2007 — CESPE/UnB) A sentença transitada em julgado adquire eficácia, tornando-se imutável e, para se preservar o princípio da segurança jurídica, não se admite a ação rescisória quando a questão nela decidida contrariar literal disposição de súmula vinculante ou violar lei inconstitucional ou, ainda, quando o STF declarar a inconstitucionalidade da lei aplicada pela decisão.

6. (PGE PB-UnB/CESPE 2008) Acerca do controle difuso de controle de constitucionalidade das leis, assinale a opção correta.

- a) A competência do STF para julgar, em sede de recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal, não tem por finalidade promover a defesa do pacto federativo, mas a compatibilidade da lei estadual em face da lei federal.
- b) No âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a liminar pode ser

preliminar da repercussão geral. Nessa hipótese, os recursos sobrestados devem ser encaminhados, pelos tribunais, turmas de uniformização ou turmas recursais, ao STF para que ele aplique aquele entendimento.

- d) O STF, de forma excepcional, tem admitido eficácia *ex nunc* às declarações de inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso.
- e) Não é possível a utilização da via da ação civil pública para declarar, mesmo que incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei, sob pena de usurpação da competência do STF, já que a sentença proferida naquela ação tem eficácia *erga omnes*.

7. (DP/AC/CESPE/UnB/2008) São desprovidas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle difuso de constitucionalidade de leis federais.

8. (Exame da OAB Unificado 2010.1 — CESPE/UnB — caderno Miguel Reale) Assinale a opção correta a respeito da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, de acordo com o que dispõe a Lei n. 9.868/1999.

- a) Essa medida cautelar só poderá ser concedida se ouvidos, previamente, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República.
- b) A decisão proferida em sede de cautelar, seja ela concessiva ou não, será dotada de eficácia contra todos, com efeito *ex nunc*, salvo se o STF entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.
- c) O relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, submeter o processo diretamente ao STF, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.
- d) Tal medida não poderá ser apreciada em período de recesso ou férias, visto que é imperioso que seja concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

9. (Procurador do Estado/RO — FCC/2011) É uma das características da ação direta de inconstitucionalidade no controle abstrato das normas na Constituição Federal brasileira:

- a) Não admitir o efeito repristinatório. A declaração de nulidade total de uma norma sempre

cria um vácuo legislativo que só pode ser sanado pelo Poder Legislativo competente.

- b) Permitir a intervenção de terceiros e do *amicus curiae*.
- c) Resultar em uma decisão judicial final com efeito *ex tunc* sempre, não se admitindo a modulação de efeitos pelo Poder Judiciário.
- d) Não admitir a declaração parcial de nulidade da norma sem a redução do texto original.
- e) A ativação do efeito repristinatório quando houver o silêncio na medida cautelar que suspende determinada lei, de modo que, a legislação anterior, se existente, torne-se novamente aplicável.

10. (OAB — VIII Exame Unificado — FGV/2012) Pode o Presidente da República editar medida provisória contrária à súmula vinculante editada pelo STF?

- a) Não, pois o STF é o guardião da Constituição.
- b) Não, pois a súmula vincula todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).
- c) Sim, pois a súmula vincula a Administração Pública, mas não o chefe do Poder Executivo.
- d) Sim, pois o Presidente da República estaria, nesse caso, exercendo função legislativa.

■ 6.10.5. Outras questões

1. (MP/74.º-1992) Enquanto não for reconhecida pelo Poder Judiciário a inconstitucionalidade de uma lei, ela obriga os particulares? Justifique.

2. (CESPE/UnB — Defensoria Pública DF — 2006) A respeito da interpretação constitucional, julgue o item seguinte:

Na declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade e a mutação constitucional, o intérprete constitucional não vê ainda na norma uma inconstitucionalidade evidente, porque ela mantém parte de sua significância em contato harmônico com a Constituição Federal, mas o julgador sinaliza, com a expressão em “trânsito para a inconstitucionalidade”, que a norma está a um passo da inconstitucionalidade, bastando, para tanto, apenas alguma alteração fática.

3. (CESPE/UnB — Defensoria Pública DF — 2006) Com relação à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), julgue os itens subsequentes.

3. (CESPE/UnB — Defensoria Pública DF — 2006) Com relação à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), julgue os itens subsequentes.

1. As declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal.
2. O ordenamento constitucional brasileiro, embora não tenha sido expresso em tal sentido, estendeu ao legislador os efeitos vinculantes da decisão de inconstitucionalidade, pois, se assim não fosse, haveria comprometimento da relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o legislador, reduzindo o Poder Judiciário a um papel subalterno perante o Poder Legislativo.
3. O STF reconheceu que a interpretação conforme a Constituição Federal, quando fixada no juízo abstrato de normas, corresponde a uma pronúncia de inconstitucionalidade. Portanto, o tribunal tem considerado inadmissível a utilização da representação interpretativa, entendendo que, quando for o caso de aplicar o princípio da interpretação conforme a Constituição Federal, deve-se fazê-lo na esfera do controle abstrato de normas.

4. (CESPE/UnB — Defensoria Pública DF — 2006) A respeito do controle de constitucionalidade das leis municipais, julgue os próximos itens.

1. É possível aplicar o efeito *ex nunc* à declaração de inconstitucionalidade de lei municipal em processo de controle difuso.
2. Apenas a Constituição estadual ou a Lei Orgânica do Distrito Federal, quando for o caso, pode servir como referência ou paradigma de confronto para efeito de controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos locais. Não se permite a utilização da Constituição da República para esse fim nas ações diretas ajuizadas perante os tribunais de justiça estaduais ou do DF.
3. A competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade em que se impugna norma local contestada em face de Carta estadual é do tribunal de justiça respectivo. Essa regra não se aplica quando o preceito atacado se revela como pura repetição de dispositivos da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos estados.

5. (TJ/DF-2007) Tendo em vista os mais recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, acerca do tema do controle de constitucionalidade de normas, é correto afirmar:

- c) Admite-se o instrumento da Reclamação mesmo por quem não tenha participado do processo objetivo em que restou fixada a tese jurídica invocada;
- d) Não se admite a técnica de limitação de efeitos em sede de controle difuso.

6. (TJ/PR-2007) Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da hierarquia das normas constitucionais são pressupostos para que o Supremo Tribunal Federal possa realizar a interpretação conforme a Constituição.
- b) A interpretação conforme a Constituição proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com ou sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do poder público.
- c) A lei municipal objeto de ação de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual será analisada pelo Tribunal de Justiça da respectiva unidade da Federação em que se encontre o município.
- d) A ação direta de inconstitucionalidade interventiva que tem por finalidade a proteção dos princípios sensíveis, entre eles a dignidade da pessoa humana, pode ser proposta pelos mesmos membros legitimados para interpor a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

7. (DP/SC/ACAFE-2008) Sobre o Controle de Constitucionalidade, todas as alternativas estão corretas, exceto a:

- a) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
- b) No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
- c) Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade associação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
- d) Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

8. (TJ/AL/CESPE/UnB/2008) Quanto aos tratados internacionais, assinale a opção

correta:

- a) Para um tratado internacional ser incorporado ao direito interno, deve ser submetido ao crivo do Congresso Nacional, ao qual compete aprová-lo por meio de resolução.
- b) O tratado internacional poderá ser objeto de ADI logo após sua promulgação pelo presidente da República.
- c) Conforme entendimento do STF, a União não pode, por meio de tratado internacional, criar isenções de tributos estaduais, sob pena de violar pacto federativo.
- d) Para a teoria monista, adotada no Brasil, existe uma só ordem jurídica — englobando o direito interno e o direito internacional — para cada Estado. Essa teoria monista, por sua vez, divide-se em duas correntes doutrinárias: a que defende a primazia do direito internacional sobre o direito interno (monismo radical), e a corrente que os equipara, dependendo a prevalência de uma norma sobre a outra da ordem cronológica de sua criação (monismo moderado).
- e) Qualquer tratado, depois de incorporado, passa a gozar do *status* de norma constitucional.

9. (Magistratura-RR/FCC/2008) Existindo comprovada controvérsia constitucional sobre dispositivo de lei estadual anterior à Constituição da República, detém o Governador do Estado legitimidade para propor, perante o Supremo Tribunal Federal,

- a) ação direta de inconstitucionalidade.
- b) arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- c) ação declaratória de constitucionalidade.
- d) mandado de injunção.
- e) mandado de segurança.

10. (CESPE/UnB — Proc. Município — SEMAD/SE) O amicus curiae não tem legitimidade para recorrer de decisões proferidas em ação declaratória de inconstitucionalidade, salvo daquelas que não o admitam como tal no processo.

11. (AGU — CESPE — 2010) No que concerne ao controle concentrado de constitucionalidade, julgue o seguinte item:

Para o STF, o indeferimento da medida cautelar na ADI não significa confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante.

Para o STF, o indeferimento da medida cautelar na ADI não significa confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante.

12. (Analista do MPSE — Área Direito — FCC/2010) Em matéria de ação direta de inconstitucionalidade, é certo que:

- a) O Supremo Tribunal Federal aprecia a validade dos dispositivos legais indicados no pedido formulado pelo autor da ação, porém admite a inconstitucionalidade por “arrastamento” ou por atração.
- b) A declaração de inconstitucionalidade, de regra, começa a produzir efeitos sempre após o trânsito em julgado da decisão, e excepcionalmente, a partir da publicação do Acórdão na imprensa oficial.
- c) A decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação direta é recorrível, cabendo também a interposição de embargos declaratórios e de ação rescisória.
- d) O Supremo Tribunal Federal fica vinculado aos fundamentos apresentados pelo proponente, por ser a causa de pedir restrita ou fechada, vedando-se que a decisão seja assentada em qualquer parâmetro constitucional.
- e) A função do Procurador-Geral da República, no controle abstrato, é a defesa das normas federais ou estaduais, cuja inconstitucionalidade é arguida, tendo assim, o papel de curador da presunção de constitucionalidade.

13. (Defensoria Pública da União — CESPE/UnB — 2010) No que se refere ao controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte:

A legislação em vigor não admite a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

14. (XXXII MP/RJ — 2011) Considere as seguintes assertivas sobre o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos na Constituição da República:

- I. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
- II. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de

República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político independente de representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

- III. O controle concentrado de constitucionalidade no âmbito dos estados surgiu no Ordenamento Jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 1988.
- IV. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
- V. Nas ações diretas de inconstitucionalidade de lei estadual ou municipal em face da Constituição Estadual, a decisão final do Tribunal de Justiça só estará sujeita à apreciação do Supremo Tribunal Federal, via recurso extraordinário, se o preceito da Carta Estadual violado for daqueles de repetição obrigatória, decorrente da Constituição da República.

As afirmativas corretas são somente:

- a) I, II e IV.
- b) I, III e V.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e IV.
- e) II, IV e V.

15. (Analista Judiciário — TRT-11/AM — Área Administrativa — FCC/2012) Sobre as medidas judiciais de controle da constitucionalidade brasileira analise as seguintes assertivas:

- I. A ADPF, decorrente da Constituição Federal, será apreciada pelo STF, na forma da lei.
- II. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- III. O Presidente do Senado Federal é um dos legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I e II.
- b) I e III.

- c) II e III.
- d) II.
- e) III.

16. (Magistratura/TJ-RJ — VUNESP/2011) Considerando o sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos no direito brasileiro, é correto afirmar que:

- a) para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática.
- b) em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, o STF firmou o entendimento de que ação dessa natureza não é suscetível de desistência.
- c) a medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia *ex tunc*, operando, portanto, desde a edição da lei ou do ato normativo atacado.
- d) quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no STF, contra a mesma lei estadual em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da CF, a ação direta proposta perante o Tribunal estadual deve ser extinta.

17. (Procurador da Assembleia Legislativa/ES — CESPE/UnB/2011) No que diz respeito às ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, assinale a opção correta:

- a) As leis municipais não podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF.
- b) O STF admite a alegação de prescrição ou decadência para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em relação a lei ou ato normativo.
- c) A decisão proferida pelo STF no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade passa a produzir efeitos a partir do trânsito em julgado da respectiva decisão.
- d) As deliberações administrativas dos tribunais de justiça dos estados não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
- e) Segundo entendimento do STF, não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental que tenha por objeto súmulas vinculantes.

18. (Magistratura/TRF1 — CESPE/UnB/2011) Considerando a disciplina constitucional a respeito do controle de constitucionalidade das leis e dos atos

fundamental que tenha por objeto súmulas vinculantes.

18. (Magistratura/TRF1 — CESPE/UnB/2011) Considerando a disciplina constitucional a respeito do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, assinale a opção correta.

- a) A ADI admite a intervenção de terceiros, mas a ADC, não.
- b) Uma vez proposta a ADI por omissão, todos os demais legitimados podem manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais.
- c) Sendo a ADPF espécie de controle concentrado que visa evitar ou reparar lesão às normas que, materialmente constitucionais, fazem parte da Constituição formal, e não à Constituição em seu conjunto, não cabe reclamação para o STF no caso de descumprimento da decisão.
- d) O STF, seguindo a doutrina constitucional majoritária, entende que a ADPF é cabível contra ato do poder público de natureza administrativa ou normativa, mas não contra ato judicial.
- e) A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo STF está sujeita à manifestação, em um ou em outro sentido, de, pelo menos, oito ministros, quer se trate de ADI, quer se trate de ADC.

19. (Procurador Municipal — Prefeitura de Nova Lima/MG — FUMARC/2011) Ainda sobre o controle de constitucionalidade, são verdadeiras as assertivas abaixo, EXCETO:

- a) Caberá recurso extraordinário para o STF da decisão prolatada pelo tribunal de justiça estadual em controle abstrato de constitucionalidade apenas quando possa ter por parâmetro de controle norma da Constituição Estadual que seja reprodução obrigatória de norma da Constituição da República.
- b) A existência simultânea de representação de inconstitucionalidade perante o tribunal de justiça estadual e de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal impõe a suspensão da primeira até o julgamento final da última.
- c) A Ordem dos Advogados do Brasil, como parte legitimada a instaurar o controle concentrado de constitucionalidade, deve demonstrar a pertinência temática da norma impugnada com as suas atribuições institucionais.
- d) Pode haver a modulação dos efeitos da decisão do tribunal de justiça estadual no âmbito da representação de inconstitucionalidade estadual.

Estado. A referida lei é:

- a) compatível com a Constituição da República, desde que a Constituição do Estado-membro não reserve à Chefia do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos estaduais.
- b) constitucional, em que pese o vício de iniciativa, pois a sanção do Governador do Estado ao projeto de lei teve o condão de sanar o defeito de iniciativa.
- c) inconstitucional, uma vez que os projetos de lei de iniciativa dos Deputados Estaduais não se submetem à sanção do Governador do Estado, sob pena de ofensa à separação de poderes.
- d) inconstitucional, uma vez que são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos da administração direta e autárquica estadual.

21. (Delegado de Polícia Civil/ES — CESPE/UnB/2011) Com relação ao processo legislativo e ao controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte.

Considere que o TJ do Estado tenha julgado procedente ADI que teve por objeto lei municipal, sob o fundamento de afronta a dispositivo inserto na Constituição Estadual, o qual se limitou a reproduzir preceito da CF de observância obrigatória pelos Estados. Nessa hipótese, segundo entendimento do STF, não é viável a utilização de qualquer espécie recursal contra a referida decisão para fins de submissão do tema à jurisdição da Corte Suprema, por tratar-se de decisão proferida no âmbito do controle abstrato de normas e por ter tido como objeto lei municipal.

22. (Auditor Fiscal da Receita Estadual — SEFAZ-RJ — FGV/2011) Suponha que o STF, em ação direta de inconstitucionalidade (ADI), tenha julgado a lei X inconstitucional. Nesse caso, seria correto afirmar que a lei X:

- a) é federal e deverá ser encaminhada ao Senado para que seja suspensa.
- b) pode ser federal ou estadual e deverá ser encaminhada ao Senado para que seja suspensa.
- c) pode ser federal, estadual ou municipal e deverá ser encaminhada ao Senado para que seja suspensa.
- d) pode ser federal, estadual ou municipal e não precisa ser encaminhada ao Senado para ser suspensa.
- e) pode ser federal ou estadual e não precisa ser encaminhada ao Senado para ser suspensa.

23. (Juiz do Trabalho — TRT/23 — MT/2011) Assinale certo ou errado (questão adaptada pelo autor, já que a versão original é de múltipla escolha, com 5 alternativas):

Normas constitucionais interpostas seriam aquelas disposições normativas às quais as normas constitucionais fazem expressa referência, vinculando atos e procedimentos legislativos, apresentando uma força normativa diferenciada por derivar diretamente da referência constitucional.

24. (Analista Ministerial — MP/PI — Área Processual — CESPE/UnB/2012) Acerca do controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico nacional, julgue o item subsecutivo:

No âmbito do denominado controle difuso concreto, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade pode excepcionalmente não ter efeitos retroativos, assim como ocorre na ação direta de inconstitucionalidade, no âmbito da qual se admite, inclusive, a oposição de embargos de declaração para fins de modulação de efeitos da decisão.

25. (TRT1 — Analista Judiciário — FCC/2013) Na hipótese de uma Turma do Tribunal Regional do Trabalho deparar-se com questão ainda não examinada pelo Supremo Tribunal Federal, atinente à constitucionalidade de lei, prejudicial à decisão de um caso concreto submetido a seu julgamento, o órgão julgador, em virtude do quanto dispõe a Constituição da República:

- a) estará impedido de pronunciar-se, até que sobrevenha decisão sobre a constitucionalidade da lei proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual compete a guarda da Constituição.
- b) estará impedido de pronunciar-se, até que sobrevenha decisão sobre a constitucionalidade da lei proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, instância jurisdicional final em matéria trabalhista.
- c) poderá afastar a incidência da lei, desde logo, mas não declarar sua inconstitucionalidade expressamente, sem que haja decisão anterior proferida a esse respeito pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Regional do Trabalho ou de seu Órgão Especial.
- d) não poderá declarar a inconstitucionalidade da lei, tampouco afastar sua incidência, sem que haja decisão anterior proferida a esse respeito pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Regional do Trabalho ou de seu Órgão Especial.
- e) poderá declarar a inconstitucionalidade da lei, bem como afastar sua incidência,

- d) não poderá declarar a inconstitucionalidade da lei, tampouco afastar sua incidência, sem que haja decisão anterior proferida a esse respeito pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Regional do Trabalho ou de seu Órgão Especial.
- e) poderá declarar a inconstitucionalidade da lei, bem como afastar sua incidência, independentemente da existência de decisão anterior proferida a esse respeito por outras instâncias da Justiça do Trabalho ou pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de decisão a ser tomada em sede de controle difuso de constitucionalidade.

26. (Juiz-Auditor da Justiça Militar da União/STM — CESPE/UnB/2013) Assinale a opção correta acerca do controle de constitucionalidade, de acordo com a CF e a jurisprudência do STF:

- a) A inconstitucionalidade reflexa consiste em técnica de decisão judicial que visa à declaração de que a permanência de determinadas circunstâncias fáticas e (ou) jurídicas implica considerar determinada lei ainda constitucional, até que ocorra mudança no contexto fático-jurídico.
- b) A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo STF vincula, inclusive, o próprio STF.
- c) Verifica-se inconstitucionalidade por arrastamento vertical quando há relação hierárquica entre as normas dependentes, de forma que o advento da declaração de inconstitucionalidade da norma hierarquicamente superior implica perda de validade da norma inferior por inconstitucionalidade consequencial.
- d) É vedada ao tribunal de contas a apreciação, no uso de suas atribuições, da constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.
- e) Caracteriza-se a inconstitucionalidade progressiva quando o vício irrogado a um ato normativo é o desrespeito à CF por violação a norma infraconstitucional interposta.

27. (Defensor Público/RR — CESPE/UnB/2013) No que concerne às ações por meio das quais o STF realiza o controle concentrado de constitucionalidade, assinale a opção correta.

- a) No exercício do juízo de admissibilidade, o ministro relator poderá indeferir de plano a ação declaratória de constitucionalidade, em decisão da qual não caberá recurso.
- b) Não é cabível a concessão de medida liminar na ADI por omissão.
- c) Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, é vedada a concessão de medida liminar *inaudita altera partes*.
- d) O STF admite o ingresso de *amicus curiae* na ADI, reconhecendo-lhe o direito de aditar o

28. (Magistratura/MA — CESPE/UnB/2013) À luz da jurisprudência do STF, assinale a opção correta em relação ao exercício do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade.

- a) Não é admitida a participação do *amicus curiae* na ADI por omissão.
- b) É cabível a intervenção de terceiros na arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- c) De acordo com o STF, não é admissível o ajuizamento de ADI contra ato estatal de conteúdo derogatório, ou seja, contra resolução administrativa normativa que incida sobre atos normativos.
- d) Para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, o partido político com representação no Congresso Nacional deve estar representado por advogado.

■ GABARITO ■

■ 6.10.1. Conceitos gerais
1. “c”. Trata-se de controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Legislativo (CN), exceção à regra geral do controle de constitucionalidade jurisdicional misto (difuso e concentrado), pelo qual o controle é exercido por órgão do Poder Judiciário.
2. “c”. Em igual sentido, cf. exame 119.º da OAB.
3. “c”.
4. “a”. A ementa esclarece o assunto: “Como o parecer da Consultoria-Geral da República (SR n. 70, de 6.10.88, <i>DO</i> de 7.10.88), aprovado pelo Presidente da República, assumiu caráter normativo, por força dos arts. 22, § 2.º, e 23 do Decreto n. 92.889, de 7.7.86, e, ademais, foi seguido de circular do banco central, para o cumprimento da legislação anterior à Constituição de 1988 (e não do § 3.º do art. 192 desta última), pode ele (o parecer normativo) sofrer impugnação, mediante ação direta de inconstitucionalidade, por se tratar de ato normativo federal (art. 102, I, <i>a</i> , da CF)” (ADI 4/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, <i>DJ</i> de 25.06.1993, p. 12637, <i>Ement.</i> v. 01709-01, p. 00001; Julgamento: 07.03.1991, Tribunal Pleno). Apesar de ser outro assunto discutido nessa questão, como a <i>ementa</i> fala no art. 192, § 3.º, convém lembrar o candidato

estudioso que referido parágrafo foi expressamente revogado pela EC n. 40/2003!
5. “d”. Em regra, todo decreto presidencial, como visto na parte teórica, por regulamentar lei, sofre controle de legalidade e não de constitucionalidade, salvo se, em situações excepcionais, estivermos diante de decreto autônomo. Trata-se daquilo que o STF chamou de crise de legalidade, caracterizada pela inobservância do dever jurídico de subordinação normativa à lei, escapando das balizas previstas na Constituição Federal.
6. “e”.
7. “certo”. Sinceramente, ficamos muito honrados com esta questão, na medida em que demonstra que a importante instituição do CESPE/UnB adotou a nossa classificação de vício de decoro parlamentar (cf. <i>item 6.3.4</i>). Referido item, ao final, foi anulado em decorrência do uso equivocado da letra “Y” no lugar da letra “W”, o que prejudicou o julgamento objetivo da assertiva. De qualquer maneira, de fato, diante da nossa proposta, não há dúvida de que a Lei “W” padece do <i>vício de decoro parlamentar</i> .
8. “certo”.
9. “certo”.
10. “a”.
11. “c”. O art. 26 da Lei n. 9.868/99 estabelece: “a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória”.
12. “e”.
13. “a”.
14. “errado”. Cf., além das matérias discutidas neste capítulo, o <i>item 19.2.4</i> .
■ 6.10.2. Legitimidade
1. “d”. Quem é legitimada é a entidade de classe de âmbito nacional, cf. art. 103, IX.

■ 6.10.2. Legitimidade

1. “d”. Quem é legitimada é a entidade de classe de âmbito nacional, cf. art. 103, IX.

2. “c”. Antes da EC n. 45/2004, os legitimados para a propositura da referida ação eram apenas quatro, de acordo com o art. 103, § 4.º, da CF/88, quais sejam: *a)* Presidente da República; *b)* Mesa do Senado Federal; *c)* Mesa da Câmara dos Deputados; *d)* Procurador-Geral da República. Com a revogação do § 4.º e a nova redação do *caput* do art. 103, pela aludida emenda, os legitimados para a propositura da ADC passaram a ser os mesmos da ADI genérica (*vide item 6.7.1.14*).

3. “d”. Art. 36, III, c/c o art. 34, VII, “b”, da CF/88 (ADI interventiva federal). Lembramos que a decretação e execução da intervenção federal é ato de competência privativa do Presidente da República (art. 84, X), caso a decretação da suspensão da execução do ato do Governador de Estado (também por decreto presidencial) não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade (art. 36, § 3.º).

4. “certo”. Como sempre afirmamos, a prova do CESPE/UnB exige conhecimento da jurisprudência do STF!

5. “certo”, nos termos do art. 12-A da Lei n. 9.868/99 c/c art. 103 da CF/88.

6. “e”. Conforme visto, o art. 125, § 2.º, autoriza a leitura simétrica do art. 103 (cf. *item 6.8.4*).

7. “certo”. Conforme jurisprudência do STF exposta na parte teórica.

8. “d”.

■ 6.10.3. Procedimento

1. “d”. De acordo com o art. 52, X, da CF/88.

2. “c”. De acordo com o art. 14, I a III, e parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, bem como jurisprudência do STF.

3. “Anulada”. De fato, as alternativas “a”, “b” e “c” estão todas previstas e admitidas no art. 9.º, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, que disciplinou o processo e julgamento da ADI. As alternativas “d” e “e”,

como a desistência da ação (art. 5.º, <i>caput</i>, da Lei). Como não se admitem duas alternativas corretas neste teste, ele teve de, corretamente, ser anulado. Lembramos ao candidato atento outras características do procedimento da ADI, vistas na parte teórica: <i>a</i>) inexistência de prazo prescricional ou decadencial; <i>b</i>) irrecorribilidade da decisão, salvo a interposição de embargos declaratórios; <i>c</i>) não rescindibilidade da decisão proferida, tudo em razão da natureza objetiva do processo de ADI.
4. “b”. Cf. arts. 5.º, VI, e 19, I. No mais, de modo correto, a impugnação deve-se dar não por ADI, mas por arguição, já que, nos termos do art. 102, I, “a”, lei municipal não pode ser objeto de ADI. Como ainda não há julgamento pelo STF em relação à constitucionalidade da arguição por equiparação, conforme advertido, nos testes, adotar a regra da Lei n. 9.882/99, que prevê, dentre os objetos da arguição, a lei municipal.
5. Cf. parte teórica, <i>item 6.7.1.16</i>.
6. “e”.
7. “c”. Confira parte teórica e RE 453.744-AgR.
8. “errado”.
9. “c”. Nos termos do art. 125, § 2.º, e jurisprudência apontada na parte teórica. A letra “a” está errada por violar o art. 103, c/c o art. 125, § 2.º (<i>vide</i> parte teórica). A letra “b” deve ter gerado muita dúvida. De fato, a regra do art. 26 da Lei n. 9.868/99, que só admite os embargos, deve ser ampliada no caso do controle estadual, pois, excepcionalmente, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória, caberá a interposição de RE ao STF (cf. <i>item 6.8.6</i>). Essa questão confirma a tendência de extrema dificuldade no Exame de Ordem. A letra “d” está errada, pois, em muitos temas, essa reprodução vai acontecer.
10. “c”. De acordo com a novidade prevista nos arts. 12-F e 12-G da Lei n. 9.868/99, introduzidos pela Lei n. 12.063/2009. Em relação à alternativa “d”, de fato, a lei fala em agravo para o Pleno em razão de indeferimento da petição inicial pelo Relator e correta essa frase quando da realização da prova. Contudo, devemos lembrar que, de acordo com o CPC/2015, com <i>vacatio legis</i> de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de agravo interno para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-

lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de 15 dias (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em dias úteis.

11. “certo”.

■ 6.10.4. Efeitos da decisão

1. “d”. Lembramos que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (art. 5.º, § 3.º, da CF/88, introduzido pela *EC n. 45/2004*). Mesmo nessa hipótese, entendemos que a resposta continuaria sendo a mesma!

2. “a”. Como regra geral, conforme vimos na parte teórica, a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, em abstrato, em tese, marcado pela generalidade, impessoalidade e abstração, faz instaurar um processo objetivo, sem partes, no qual inexistente litígio referente a situações concretas ou individuais (*RTJ* 147/31, Rel. Min. Celso de Mello), tornando os atos inconstitucionais nulos e, por consequência, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, com alcance, de modo vinculado e para todos, sobre os atos pretéritos, fazendo com que, dentre tantos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo que tenha “revogado” outro ato normativo (nossa análise neste ponto refere-se à ADI perante o STF, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou distrital desde que no exercício da competência estadual) provoque o restabelecimento do ato normativo anterior. Para recordar, os efeitos gerais da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, por meio de ADI, são: *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, podendo ser dado efeito *ex nunc*, ou a partir de outro momento que venha a ser fixado (exceção à regra geral do princípio da nulidade), desde que a votação tenha sido por 2/3 dos Ministros, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. CUIDADO: o STF vem utilizando a terminologia “efeito repristinatório” (cf. ADI 2.215-PE, medida cautelar, Rel. Min. Celso de Mello, *Inf.* 224/STF).

3. “e”. Nos termos do art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99, “a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”. Assim, de maneira correta o constituinte determinou o respeito à coisa julgada. Em relação à

3. “e”. Nos termos do art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99, “a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”. Assim, de maneira correta o constituinte determinou o respeito à coisa julgada. Em relação à alternativa “d”, de fato, a lei fala em agravo para o Pleno em razão de indeferimento da petição inicial pelo Relator e correta essa frase quando da realização da prova. Contudo, devemos lembrar que, de acordo com o CPC/2015, com <i>vacatio legis</i> de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de agravo interno para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de 15 dias (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em dias úteis.
4. “c”.
5. “errado”. Cf. parte teórica <i>item 6.7.1.17.4</i>.
6. “d”.
7. “certo”. Isso demonstra que o CESPE, na medida em que o STF ainda não julgou a Rcl 4.335/AC, parece não estar adotando a teoria da abstração (cf. <i>item 6.6.5</i>).
8. “c”. De acordo com o art. 12 da Lei n. 9.868/99. A letra “a” está errada porque a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo de três dias, só caberá se o Relator julgar indispensável. A letra “b” está errada, na medida em que o efeito vinculante se verificará apenas em caso de concessão da cautelar. A letra “d” está errada, pois é perfeitamente possível a análise de cautelar durante o recesso, aliás, por ser cautelar, deve haver um mecanismo para tanto. A diferença é que, durante o recesso, a apreciação se dará pelo Min. Presidente do STF e, fora do recesso, pela maioria absoluta dos Ministros (cf. art. 10, <i>caput</i>, da Lei n. 9.868/99).
9. “e”. Nos termos do art. 11, § 2.º, da Lei n. 9.868/99, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

■ 6.10.5. Outras questões

1. Sim, ninguém pode alegar a referida inconstitucionalidade para justificar uma eventual recusa em cumpri-la. Apesar disso, através do controle difuso, o particular pode questionar a sua inconstitucionalidade e, então, após decisão judicial, deixar de cumpri-la. Por outro lado, complementando essa resposta, entendemos que os chefes do Executivo e do Legislativo poderiam, em casos excepcionais, desde que entendessem uma lei flagrantemente inconstitucional, determinar o seu não cumprimento administrativamente, na medida em que devem respeitar sempre a estrita legalidade de normas constitucionais. É claro que tal atitude poderá ser questionada perante o Judiciário. Esta é a posição do STF, publicada na *RTJ* 151/331, e pedimos vênias para transcrever um trecho da *ementa*: “em nosso sistema jurídico, não se admite declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo com força de lei por lei ou por ato normativo com força de lei posteriores. O controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e Legislativo, por sua Chefia — e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade —, podem tão só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais...” (ADI 221-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 22.10.1993, p. 22251, *Ement.* v. 01722-01, p. 28 — grifamos).

2. “certo”.

3. O item 1 é *errado*. Isso porque generaliza em relação “aos órgãos do Poder Judiciário”. Esse é o erro, já que a vinculação se dá em relação “aos demais órgãos do Poder Judiciário”, não se podendo falar em vinculação do próprio STF. Outrossim, como inclusive reconhecido pelo CESPE, não há referência expressa na assertiva de que se tratava das hipóteses de controle concentrado perante o STF. O item 2 está *errado* também, já que o efeito vinculante das decisões se restringe aos demais órgãos do Poder Judiciário e em relação à Administração Pública, não produzindo efeitos sobre o legislador, no exercício de sua função típica de legislar, sob pena de *fossilização*. Por fim, o item 3 está *certo*.

4. O item 1 está *certo*. O *leading case* foi o julgamento do RE 197.917, pelo qual o STF reduziu o número de vereadores do Município de Mira Estrela de 11 para 9 e determinou que a aludida decisão só atingisse a próxima legislatura (cf. íntegra do voto em *Inf. 341/STF*, Rel. Min. Maurício

correta, como o próprio CESPE reconheceu, “o item não fez menção à hipótese excepcional em que a Constituição Federal pode servir de referência para efeito de controle concentrado de lei local, que é aquela em que se tem uma norma de reprodução da Constituição Federal na Constituição do Estado-membro” e se admite a propositura de recurso extraordinário para o STF. O item 3 está <i>errado</i>, já que a regra de competência do TJ local, tendo a CE como paradigma para o confronto e controle da lei local, continua mesmo na hipótese de dispositivos de observância obrigatória. O que aconteceria, neste caso, seria, como visto na parte teórica, a simultaneidade de ações e a suspensão do julgamento da ação estadual.
5. “c”.
6. “d”.
7. “c”.
8. “b”.
9. “b”. Muito interessante a questão, consagrando a ideia de que, de fato, é a ADPF um instrumento para o controle em abstrato de recepção.
10. “certo”. Cf. <i>item 6.7.1.16.9</i> da parte teórica e ADI 3.615-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.03.2008, <i>DJE</i> de 25.04.2008 — no mesmo sentido, cf. ADI 2.591-ED. O tema está sendo revisto no julgamento da ADI 3.396 (matéria pendente).
11. “certo”.
12. “a”. <i>Vide</i> parte teórica.
13. “errado”. Cf. Lei n. 12.063/2009, que acrescentou dispositivos à Lei n. 9.868/99. Querido leitor, veja como é a “vida” dos concursos... À época, mal saiu a lei e já caiu na prova! Então, mantenham-se atentos e não desistam.
14. “c”. <i>Item I</i> <i>correto</i> nos termos da literalidade do art. 103-A, <i>caput</i>, da CF/88. O <i>item II</i> está <i>errado</i> porque o partido político, para ajuizar referidas ações, deve possuir representação no Congresso Nacional (art. 103, VIII). Mais uma vez, repete-se a necessidade de conhecimento do art. 103 (portanto, decorem!). O <i>item III</i> está <i>errado</i>, já que o controle concentrado não é novidade do texto de 1988. Desde a Constituição de 1934 já se falava em ADI Interventiva, assim como a

14. “c”. <i>Item I</i> <i>correto</i> nos termos da literalidade do art. 103-A, <i>caput</i>, da CF/88. O <i>item II</i> está <i>errado</i> porque o partido político, para ajuizar referidas ações, deve possuir representação no Congresso Nacional (art. 103, VIII). Mais uma vez, repete-se a necessidade de conhecimento do art. 103 (portanto, decorem!). O <i>item III</i> está <i>errado</i>, já que o controle concentrado não é novidade do texto de 1988. Desde a Constituição de 1934 já se falava em ADI Interventiva, assim como a EC n. 16/65 introduziu a representação de inconstitucionalidade no STF, tendo como legitimado exclusivo o PGR. O <i>item IV</i> está <i>correto</i>, nos termos do art. 103, § 2.º. Finalmente, o <i>item V</i> está <i>correto</i> conforme apontado na parte teórica, qual seja, a peculiar utilização do RE no controle concentrado estadual e, apenas, no caso de normas de repetição obrigatória ou compulsória.
15. “a”. Questão básica. O erro no <i>item III</i> está no fato de o <i>Presidente do SF</i> não ser legitimado, já que não está elencado no art. 103 da CF/88.
16. “b”. Nesse sentido, o art. 5.º, <i>caput</i>, da Lei n. 9.868/99 estabelece, textualmente, que, proposta a ação direta, não se admitirá desistência.
17. “e”, correta, na medida em que as súmulas vinculantes possuem procedimento próprio de revisão ou cancelamento. A <i>letra “a”</i> está errada porque a lei municipal poderá ser objeto de controle concentrado por meio da ADPF. Veja, a questão não diz por meio de ADI. Lembramos, ainda, que cabe, eventualmente, julgamento de recurso extraordinário contra acórdão do TJ que apreciou, originariamente, eventual ADI de lei municipal em face da CE, quando se tratar de norma de repetição obrigatória (cf. <i>item 6.8.6</i>). A <i>letra “b”</i> está errada conforme entendimento do STF firmado na S. 360 que não admite prazo decadencial ou prescricional, uma vez que atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso de tempo. A <i>letra “c”</i> está errada, na medida em que a jurisprudência do STF entende que a decisão passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento no <i>Diário Oficial</i>, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, “exceto nos casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão” (cf. ADI 711-QO). A <i>letra “d”</i> está errada porque, se a deliberação administrativa for marcada pela generalidade, impessoalidade e abstração, como as normas regimentais, terão caráter normativo e, então, caberá controle.
18. “b”. Nesse sentido, cf. art. 12-E, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, incluído pela Lei n. 12.063/2009.
19. “c”.
20. “d”. Nos termos do art. 61, § 1.º, II, “a”, de reprodução obrigatória no âmbito estadual.

23. “certo”.
24. “certo”. Cf. RE 197.917 — o caso estudado na parte teórica de <i>Mira Estrela</i> .
25. “d”. Art. 97 da CF/88 e SV 10/STF (cláusula de reserva de plenário).
26. “c”.
27. “e”.
28. “d”.

DIVISÃO ESPACIAL DO PODER — ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

■ 7.1. NOÇÕES PRELIMINARES

■ 7.1.1. Elementos integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado

A Constituição deve trazer em si os *elementos integrantes* (*componentes* ou *constitutivos*) do Estado, quais sejam:

- soberania;
- finalidade;
- povo;
- território.

Nesses termos, Dalmo de Abreu Dallari define **Estado** como “a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Nesse conceito se acham presentes todos **os elementos que compõem o Estado**, e só esses elementos. A noção de **poder** está implícita na de **soberania**, que, no entanto, é referida como característica da própria ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na referência expressa ao **bem comum**, com a vinculação deste a um certo **povo** e, finalmente, a territorialidade, limitadora da ação jurídica e política do Estado, está presente na

menção a determinado **território**”.[1](#)

■ 7.1.2. Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado

A organização e a estrutura do Estado podem ser analisadas sob três aspectos: **forma de governo**, **sistema de governo** e **forma de Estado**.

- **forma de governo:** República *ou* Monarquia;

- **sistema de governo:** presidencialismo *ou* parlamentarismo;

forma de Estado: Estado unitário *ou* Federação.

O Brasil adotou a **forma republicana** de governo, o **sistema presidencialista** de governo[2](#) e a **forma federativa** de Estado.[3](#)

Surge, então, o tema que passaremos a abordar, qual seja, a **forma federativa de Estado**. No entanto, primeiro e complementando essa fase introdutória, teceremos alguns comentários sobre a outra forma de Estado, não adotada pelo Brasil, mas pela maioria dos Estados da atualidade — o **Estado unitário**.[4](#)

■ 7.2. ESTADO UNITÁRIO

Doutrinariamente, costuma-se classificar o gênero Estado unitário em três espécies distintas:

- **Estado unitário puro;**

- **Estado unitário descentralizado administrativamente;**

- **Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente.**

■ 7.2.1. Estado unitário puro

Para apontar as características, singelas, sobre o Estado unitário puro, valemo-nos das palavras de Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky: “esta

forma, que se caracteriza por uma absoluta centralização do exercício do Poder, tendo em conta o território do Estado, não encontra exemplo histórico, evidentemente, por não ter condições de garantir que o Poder seja exercido de maneira eficiente”.⁵

■ 7.2.2. Estado unitário descentralizado administrativamente

O Estado unitário descentralizado administrativamente, apesar de ainda concentrar a tomada de decisões políticas nas mãos do Governo Nacional, avança descentralizando a execução das decisões políticas já tomadas. Criam-se pessoas para, em nome do Governo Nacional, como se fossem uma extensão deste (*longa manus*), executar, administrar, as decisões políticas tomadas.

■ 7.2.3. Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente

No Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente, diga-se de passagem, a forma de Estado mais comum hoje em dia, sobretudo nos países europeus, ocorre não só a descentralização administrativa mas também a política, pois, no momento da execução de decisões já tomadas pelo Governo Central, as “pessoas” passam a ter, também, certa autonomia política para decidir no caso concreto o melhor procedimento a ser empregado na execução daquele comando central.

■ 7.3. FEDERAÇÃO

■ 7.3.1. Histórico

A **forma federativa de Estado** tem sua origem nos EUA, e data de 1787.

Anteriormente, em 1776, tivemos a **proclamação da independência** das 13 colônias britânicas da América, passando cada qual a se intitular um novo

Estado, **soberano**, com plena liberdade e independência.

Os Estados resolveram formar, através de um tratado internacional, intitulado **Artigos de Confederação**, a *Confederação dos Estados Americanos*, um pacto de colaboração a fim de se protegerem das constantes ameaças da antiga metrópole inglesa. No aludido **pacto confederativo**, permitia-se a denúncia do tratado a qualquer tempo, consagrando-se, assim, o **direito de retirada**, de **separação**, de **secessão** do pacto.

A permissão do **direito de secessão** aumentava o problema das constantes ameaças e a fragilidade perante os iminentes ataques britânicos. Nesse sentido, buscando uma solução para aquela situação em que se encontravam, os **Estados Confederados** (ainda era uma Confederação de Estados soberanos) resolveram reunir-se na cidade da Filadélfia (todos, ausentando-se apenas o Estado de Rhode Island), onde, então, estruturaram as bases para a **Federação** norte-americana.⁶ Nessa nova forma de Estado proposta não se permitiria mais o direito de secessão. Cada Estado cedia parcela de sua soberania para um órgão central, responsável pela centralização e unificação, formando os **Estados Unidos da América**, passando, nesse momento, a ser **autônomos entre si**, dentro do pacto federativo.

Daí dizerem os autores que a formação da Federação dos EUA decorreu de um **movimento centrípeto**, de fora para dentro, ou seja, Estados soberanos cedendo parcela de sua soberania, em verdadeiro movimento de **aglutinação**. Veremos que no Brasil a formação, por outro lado, resultou de um movimento **centrífugo**, de dentro para fora, ou seja, um Estado unitário centralizado descentralizando-se. Em decorrência dessa razão histórica, conseguimos entender por que os Estados norte-americanos têm autonomia muito maior que os Estados-Membros brasileiros.

Apenas alertamos que no **modelo de repartição de competência** (item 7.9), bem como na **tipologia do federalismo** (item 7.3.2), a doutrina vislumbra tanto um federalismo **centrípeto** como um federalismo **centrífugo** ou por **segregação**, em **sentido diverso** do acima apresentado.

Nessa outra concepção (que **não** busca analisar o **movimento** de formação

da Federação, mas, acima de tudo, a amplitude da concentração de atribuições, a caracterizar o “tipo” de organização federal), quando se observar uma maior **concentração** de competências no ente **central**, estaremos diante do modelo **centrípeto** (ou *centralizador*); por outro lado, quando se observar uma maior **distribuição** de atribuições para os Estados-Membros, teremos um modelo **centrífugo** (ou *descentralizador*).

Nas palavras de Raul Machado Horta, “se a concepção do constituinte inclinar-se pelo fortalecimento do poder federal, teremos o *federalismo centrípeto*, que *Georges Scelle* chamou de federalismo por *agregação* ou *associação*; se, ao contrário, a concepção fixar-se na preservação do poder estadual emergirá o *federalismo centrífugo* ou por *segregação*, consoante a terminologia do internacionalista francês. Pode ainda o constituinte federal modelar sua concepção federal pelo *equilíbrio* entre as forças contraditórias da unidade e da diversidade, do localismo e do centralismo, concebendo o federalismo de *cooperação*, o federalismo de *equilíbrio* entre a União soberana e os Estados-membros autônomos”.⁷

Feita esta advertência, propomos a *esquematização* das *tipologias do federalismo*.

■ 7.3.2. Tipologias do Federalismo

■ 7.3.2.1. *Federalismo por agregação ou por desagregação (segregação)*

Essa classificação leva em conta a **formação histórica**, a **origem** do federalismo em determinado Estado, podendo ser por **agregação** ou por **desagregação**.

No **federalismo por agregação**, os Estados independentes ou soberanos resolvem abrir mão de parcela de sua soberania para agregar-se entre si e formar um novo Estado, agora, Federativo, passando a ser, entre si, autônomos. O modelo busca uma maior solidez, tendo em vista a *indissolubilidade do vínculo federativo*. Como exemplo, podemos citar a formação dos **Estados Unidos**, da

Alemanha e da **Suíça**.

Por sua vez, no **federalismo por desagregação** (*segregação*), a Federação surge a partir de determinado Estado unitário que resolve descentralizar-se, “em obediência a imperativos políticos (salvaguarda das liberdades) e de eficiência”.⁸ O **Brasil** é exemplo de federalismo por desagregação, que surgiu a partir da proclamação da República, materializando-se, o novo modelo, na Constituição de 1891.

■ 7.3.2.2. *Federalismo dual ou cooperativo*

Ao analisar o **modo** de **separação de atribuições** (competências) entre os entes federativos, a doutrina identificou tanto o federalismo **dual** como o federalismo

cooperativo.

No **federalismo dual**, a separação de atribuições entre os entes federativos é extremamente rígida, não se falando em cooperação ou interpenetração entre eles. O exemplo seriam os **Estados Unidos** em sua origem.

Flexibilizando a rigidez do modelo dual (clássico), sobrevém o modelo **cooperativo**, especialmente durante o século XX, com o surgimento do *Estado do Bem-Estar Social*, ou *Estado-providência*.

Nesse modelo, as atribuições serão exercidas de modo **comum** ou **concorrente**, estabelecendo-se uma verdadeira aproximação entre os entes federativos, que deverão atuar em **conjunto**. Assim, modernamente, percebe-se, cada vez mais, uma **gradativa substituição** do federalismo dual pelo cooperativo.

A doutrina adverte o risco de, a pretexto do modelo cooperativo, instituir-se um federalismo de “fachada”, com fortalecimento do órgão central em detrimento dos demais entes federativos e, assim, havendo sobreposição da União, a caracterização de um federalismo de subordinação.

Zimmermann, contudo, salienta que, se por um lado existe esse risco de negação do próprio federalismo, não se pode deixar de admitir o **federalismo**

cooperativo verdadeiramente **democrático**, formado “... no consentimento geral da nação, e não através da imposição do poder central”, eliminando-se, dessa forma, o autoritarismo.⁹

O modelo **brasileiro** pode ser classificado como um **federalismo cooperativo**.

■ 7.3.2.3. *Federalismo simétrico ou assimétrico*

A simetria ou assimetria do federalismo decorre dos mais variados **fatores**, seja em relação à cultura, seja no concernente ao desenvolvimento, à língua etc.

No federalismo **simétrico** verifica-se homogeneidade de cultura e desenvolvimento, assim como de língua, como é o caso dos Estados Unidos.

Por outro lado, o federalismo **assimétrico** pode decorrer da diversidade de língua e cultura, como se verifica, por exemplo, nos quatro diferentes grupos étnicos da Suíça (*cantões*), ou, também, no caso do Canadá, país bilíngue e multicultural.

No **Brasil** há certo “**erro de simetria**”, pelo fato de o constituinte tratar de modo idêntico os Estados, como se verifica na representação no Parlamento (cada Estado, não importa o seu tamanho, o seu desenvolvimento, elege o número fixo de 3 Senadores, cada qual com dois suplentes — art. 46, §§ 1.º e 3.º).

O constituinte deveria ter considerado a dimensão territorial, o desenvolvimento econômico, a cultura etc., tratando, dessa forma, de modo assimétrico os entes federativos. Essa distinção, naturalmente, não poderia significar a preferência de um ente federativo em relação a outro, sob pena de se desvirtuar o texto constitucional.

■ 7.3.2.4. *Federalismo orgânico*

No **federalismo orgânico**, o Estado deve ser considerado um “organismo”.- Busca-se, dessa forma, sustentar a manutenção do “todo” em detrimento da

“parte”.

Os Estados-Membros, por consequência, aparecem como um simples reflexo do “*todo-poderoso* poder central”.

Conforme aponta Zimmermann, “este modelo, o orgânico-federativo, parece haver se estabelecido sob as novas formulações teóricas surgidas ao longo do século XX. Movidas por concepções que visavam muito mais o estabelecimento da homogeneidade e a formulação de concepções centralistas, elas acabaram por atender, direta ou indiretamente, aos objetivos ditatoriais de governos federais socialistas e da América Latina”. [10](#)

■ 7.3.2.5. *Federalismo de integração*

Em nome da **integração nacional**, passa a ser verificada a preponderância do Governo central sobre os demais entes, atenuando, assim, as características do modelo federativo.

Nesse sentido, André Ramos Tavares constata que, “no extremo, o federalismo de integração será um federalismo meramente formal, cuja forte assimetria entre poderes distribuídos entre as entidades componentes da federação o aproxima de um Estado unitário descentralizado, com forte e ampla dependência, por parte das unidades federativas, em relação ao Governo da União federal”. [11](#)

■ 7.3.2.6. *Federalismo equilíbrio*

O **federalismo equilíbrio** traduz a ideia de que os entes federativos devem manter-se em harmonia, reforçando-se as instituições.

Segundo André Ramos Tavares, “isso pode ser alcançado pelo estabelecimento de regiões de desenvolvimento (entre os Estados) e de regiões metropolitanas (entre os municípios), concessão de benefícios, além da redistribuição de rendas”, [12](#) destacando-se, respectivamente, os arts. 43, 25, § 3.º, 151, I, e 157 a 159.

■ 7.3.2.7. *Federalismo de segundo grau*

Manoel Gonçalves Ferreira Filho fala em uma *tríplice estrutura do Estado brasileiro*, diferente, por exemplo, do modelo norte-americano que apresenta a União e os Estados-Membros.

De fato, no Brasil, é reconhecida a existência de **3 ordens**, quais sejam, a da União (*ordem central*), a dos Estados (*ordens regionais*) e a dos Municípios (*ordens locais*).

Não se pode esquecer, naturalmente, a posição peculiar do DF em nossa Federação que, a partir do texto de 1988, não tem natureza nem de Estado nem de Município, podendo ser caracterizado como “... uma *unidade federada* com autonomia parcialmente tutelada”. [13](#)

Em seguida, observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho que o poder de auto-organização dos Municípios deverá observar **dois graus**, quais sejam, a Constituição Federal e a Constituição do respectivo Estado. Assim, conclui, “a Constituição de 1988 consagra um **federalismo de segundo grau**”. [14](#)

■ 7.3.3. *Características da Federação*

Apesar de cada Estado federativo apresentar características peculiares, inerentes às suas realidades locais, encontramos alguns pontos em comum que podem assim ser sistematizados:

- **descentralização política:** a própria Constituição prevê núcleos de poder político, concedendo autonomia para os referidos entes;
- **repartição de competência:** garante a autonomia entre os entes federativos e, assim, o equilíbrio da federação;
- **Constituição rígida como base jurídica:** fundamental a existência de uma Constituição rígida no sentido de garantir a distribuição de competências entre os entes autônomos, surgindo, então, uma verdadeira **estabilidade institucional**;
- **inexistência do direito de secessão:** não se permite, uma vez criado o

pacto federativo, o direito de separação, de retirada. Tanto é que, só a título de exemplo, no Brasil, a CF/88 estabeleceu em seu art. 34, I, que a tentativa de retirada ensejará a decretação da intervenção federal no Estado “rebelante”. Eis o **princípio da indissolubilidade do vínculo federativo**, lembrando, inclusive, que a forma federativa de Estado é um dos limites materiais ao poder de emenda, na medida em que, de acordo com o art. 60, § 4.º, I, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a **forma federativa de Estado**;

■ **soberania do Estado federal**: a partir do momento que os Estados ingressam na federação perdem soberania, passando a ser autônomos. Os entes federativos são, portanto, autônomos entre si, de acordo com as regras constitucionalmente previstas, nos limites de sua competência; a **soberania**, por seu turno, é característica do todo, do “país”, do Estado federal, no caso do Brasil, tanto é que aparece como **fundamento da República Federativa do Brasil** (art. 1.º, I, da CF/88). Conforme alertamos no *item 4.7*, dentro do conceito de **supranacionalidade**, hoje se fala em **flexibilização** da ideia clássica de soberania;

■ **intervenção**: diante de situações de crise, o processo interventivo surge como instrumento para assegurar o equilíbrio federativo e, assim, a manutenção da Federação;

■ **auto-organização dos Estados-Membros**: através da elaboração das Constituições Estaduais (*vide* art. 25 da CF/88);

■ **órgão representativo dos Estados-Membros**: no Brasil, de acordo com o art. 46, a representação dá-se através do Senado Federal;

■ **guardião da Constituição**: no Brasil, o STF;

■ **repartição de receitas**: assegura o equilíbrio entre os entes federativos (arts. 157 a 159).

■ 7.3.4. Federação brasileira

■ 7.3.4.1. Breve histórico

Provisoriamente, a Federação no Brasil surge com o Decreto n. 1, de 15.11.1889, decreto esse instituidor, também, da forma republicana de governo. A consolidação veio com a primeira constituição republicana, de 1891, que em seu art. 1.º estabeleceu: “A nação Brasileira adota como forma de governo, sob o regimen representativo, a República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitue-se, por união perpetua e indissolúvel das suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brazil”. [15](#)

As Constituições posteriores mantiveram a forma federativa de Estado, porém, “não se pode deixar de registrar o entendimento de alguns, segundo o qual, nas Constituições de 1937 e de 1967, bem como durante a vigência da Emenda n. 1/69, tivemos no Brasil somente uma Federação de fachada”. [16](#)

■ 7.3.4.2. **Federação na CF/88 e princípios fundamentais** [17](#)

■ 7.3.4.2.1. **Composição e sistematização conceitual**

Preceitua o art. 1.º, *caput*, da CF/88 que a **República Federativa do Brasil** é formada pela união **indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, sendo que o *caput* de seu art. 18 complementa, estabelecendo que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União**, os **Estados**, o **Distrito Federal** e os **Municípios**, todos **autônomos**, nos termos desta Constituição”.

José Afonso da Silva esclarece o assunto: “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, como se vê do art. 18, a *União*, os *Estados*, o *Distrito Federal* e os *Municípios*. A Constituição aí quis destacar as entidades que integram a estrutura federativa brasileira: *os componentes do nosso Estado Federal*. Merece reparo dizer que é a organização político-administrativa que compreende tais entidades, como se houvesse alguma diferença entre o que aqui se estabelece e o que se declarou no art. 1.º. Dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela *união*

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal não é diverso de dizer que ela compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, porque a *união indissolúvel* (embora com inicial minúscula) do art. 1.º é a mesma União (com inicial maiúscula) do art. 18. Repetição inútil, mas que não houve jeito de evitar, tal o apego à tradição formal de fazer constar do art. 1.º essa cláusula que vem de constituições anteriores, sem levar em conta que a metodologia da Constituição de 1988 não comporta tal apego destituído de sentido. Enfim, temos aí destacados os componentes da nossa República Federativa: (a) União; (b) Estados; (c) Distrito Federal; e (d) Municípios...”. [18](#)

Então podemos esquematizar:

- **forma de governo:** republicana;
- **forma de Estado:** Federação;
- **característica do Estado brasileiro:** trata-se de Estado de Direito, democratizado, qual seja, Estado Democrático de Direito;
- **entes componentes da Federação:** União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- **sistema de governo:** presidencialista.

■ 7.3.4.2.2. **Fundamentos da República Federativa do Brasil**

O art. 1.º enumera, como **fundamentos** da República Federativa do Brasil:

soberania — fundamento da República Federativa do Brasil *e não da União, enquanto ente federativo. A soberania é do conjunto formado pela* União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

cidadania;

dignidade da pessoa humana;

valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa;

pluralismo político.

■ 7.3.4.2.3. **Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil**

■ 7.3.4.2.3.1. Art. 3.º, CF/88

Os objetivos fundamentais (e em concursos já foi necessário conhecê-los, em contraposição aos fundamentos) vêm relacionados no art. 3.º da CF/88.

Como advertiu Celso Bastos, “a ideia de objetivos não pode ser confundida com a de fundamentos, muito embora, algumas vezes, isto possa ocorrer. Os fundamentos são inerentes ao Estado, fazem parte de sua estrutura. Quanto aos objetivos, estes consistem em algo exterior que deve ser perseguido”.¹⁹ A CF/88 assim os define:

- construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- garantir o desenvolvimento nacional;
- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

■ 7.3.4.2.3.2. As alterações introduzidas pela EC n. 87/2015 em relação ao ICMS no contexto dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil

A **EC n. 87/2015**, dentro do contexto de **implementação dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil** (art. 3.º, ADCT), alterou as regras relacionadas ao **ICMS**. Inicialmente, compararemos a redação anterior e a atual, com a emenda, para que possamos entender as novidades introduzidas.

REDAÇÃO ORIGINAL	REDAÇÃO INTRODUIDA PELA EC N. 87/2015
Art. 155, § 2.º, VII — <i>em relação às</i> operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor	Art. 155, § 2.º, VII — nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte

final localizado em outro Estado, adotar-se-á:	ou não do imposto , localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;	a) (revogada);
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.	b) (revogada).

A regra **anterior** à EC n. 87/2015 foi bem delimitada pelo STF em didático voto proferido pelo Min. Joaquim Barbosa, destacando-se:

“Nosso constituinte originário optou por um modelo híbrido de partilha da competência. Nos termos do art. 155, VII da Constituição, **o Estado de origem da mercadoria foi adotado como critério-padrão**, com as seguintes especificações:

a) *Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto*: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Há, portanto, tributação concomitante, ou ‘partilha simultânea do tributo’. Quer dizer, ambos os estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas;

b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna;

c) *Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final*: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual;

d) *Se a operação envolver combustíveis e lubrificantes, há inversão*: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem” (**ADI 4.565-MC**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.

07.04.2011, Plenário, DJE de 27.06.2011, fls. 7).

Dessa forma, o constituinte originário prestigiou, em relação às **operações interestaduais**, a regra da **tributação exclusiva** pelo **Estado de origem** quando o **consumidor final não for contribuinte do ICMS** (letra “b” acima), com a sua **mitigação** na hipótese de o *consumidor final ser também contribuinte do tributo* (item “a” acima que, aliás, não é o mais comum. Normalmente, o que se verifica é um consumidor final que não é contribuinte, situação na qual, pela regra antiga, o **valor ficava todo com o Estado de origem** — art. 155, VII, “b”, antes da EC n. 87/2015); ou quando a *mercadoria for destinada a quem não é consumidor final* (letra “c”). A inversão da regra geral só foi estabelecida para a operação que envolver combustíveis e lubrificantes, quando, então, a competência para cobrança do ICMS será do **Estado de destino** da mercadoria (letra “d” acima).

A modificação do modelo estabelecido na Constituição, como bem declarou a Corte, dependeria de **alteração por emenda** (*reforma tributária*), não podendo essa opção política ser substituída por decisão judicial ou outras formas normativas de sua introdução (como leis federais ou estaduais, resoluções do Senado Federal, protocolo do Confaz etc.), mesmo diante dos argumentos, trazidos na ação, concernentes às disparidades verificadas entre os entes federativos nessas hipóteses de venda e compra de mercadorias pela *internet*, o chamado *e-commerce*.

A **evolução tecnológica e as novas formas de comércio** (*e-commerce*) impulsionaram a aprovação da EC n. 87/2015, especialmente diante do art. 3.º, II e III, CF/88, que estabelecem, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o de “garantir o desenvolvimento nacional” e o de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Na visão dos especialistas, não estabelecer nenhum valor para o Estado em que reside o comprador (já que o imposto, na regra antiga, não era devido para esse Estado nas operações interestaduais cuja mercadoria fosse destinada a consumidor final **não contribuinte**, aliás, a grande maioria das situações) seria **potencializar as desigualdades regionais**.

Como bem anotou o Deputado Márcio Macedo, Relator da *Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à PEC n. 197-A/2012*, “a configuração constitucional, com efeito, traz um desequilíbrio na repartição do ICMS incidente sobre as vendas para **consumidor final não contribuinte residente em Estado diferente do fornecedor**. Na época da aprovação da Carta, esse desequilíbrio não tinha qualquer importância, considerando o montante reduzido das operações em relação ao total da arrecadação do ICMS. No entanto, **o volume do comércio eletrônico** — forma de comercialização de bens que sequer se imaginava possível em 1988 — vem evoluindo aceleradamente, nas últimas décadas: entre os anos de 2001 e 2011, o faturamento com esse modo de aquisição de mercadorias multiplicou-se por 35, subindo de R\$ 540 milhões para quase R\$ 19 bilhões. **Esse crescimento, aliado às perspectivas favoráveis para os próximos anos, com a recuperação econômica, indica que a antiga configuração, elaborada em 1988, precisa de atualização**”.

Devemos observar que **todas** as tentativas que procuraram corrigir essa **distorção** gerada pela realidade do **comércio eletrônico** (Estados-Membros ditos “consumidores”, como os do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, estariam perdendo valores da arrecadação para os Estados ditos “produtores”, como São Paulo e Rio de Janeiro) **e que não foram implementadas por emenda constitucional**, foram declaradas **inconstitucionais pelo STF**.²⁰

Eis o objetivo da EC n. 87/2015: modificar o modelo de partilha de competências para afastar a radicalização do critério da origem e permitir que Estados consumidores finais dos produtos também ficassem com parcela do imposto.

Assim, no novo modelo, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte **ou não do imposto**, localizado em **outro Estado**, adotar-se-á a alíquota **interestadual** e caberá ao **Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual** (art. 155, § 2.º, VII, CF/88).

Essa nova regra foi implementada dentro de um **regime de transição**, já que

antes da EC n. 87/2015, quando se tratava de consumidor final **não contribuinte do ICMS**, o valor ficava todo com o Estado de origem, local em que se encontrava o vendedor.

De acordo com o **art. 99, ADCT**, para efeito do disposto no inciso VII do § 2.º do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a **consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado**, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será **partilhado** entre os Estados de origem e de destino, seguindo uma proporção até que, em 2019, o valor total dessa diferença caberá ao destino, modificando, então, por completo, o modelo até então vigente. Vejamos como se dará essa **transição**:

DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERSTADUAL		
Ano	Estado de origem	Estado de destino
■ 2015	■ 80%	■ 20%
■ 2016	■ 60%	■ 40%
■ 2017	■ 40%	■ 60%
■ 2018	■ 20%	■ 80%
■ 2019	■ 0%	■ 100%

Partindo do resumo estabelecido pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento da ADI 4.565-MC acima descrito, a EC n. 87/2015 modificou apenas a letra “b”, ou seja, as *operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a*

consumidor final **não contribuinte do imposto**. Nesse caso, a partir de 2019 (regra de transição), caberá ao **Estado de origem** aplicar a **alíquota interestadual**, e ao **Estado de destino** a **diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual**, havendo **tributação concomitante**, ou “partilha simultânea do tributo”.

Assim, imaginando que um escritório de advocacia sediado em Salvador (consumidor final não contribuinte) compre, em uma loja virtual situada em São Paulo, um computador, o ICMS incidente sobre essa circulação deverá ser assim tributado: 7% (alíquota interestadual) para o Estado de origem e, imaginando o percentual no referido Estado ser de 17%, **caberá a esse Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual**, no caso, 10% (17% – 7%).

Por fim, em total harmonia com as garantias estabelecidas no art. 150, III, “b” e “c”, CF/88, o art. 3.º da EC n. 87/2015 prescreve que a referida emenda entra em vigor na data de sua publicação (17.04.2015), **produzindo efeitos no ano subsequente (2016) e após 90 dias**. Assim, e esse tema ainda vai gerar algum debate (pendente), parece que o art. 99, I, ADCT, que fala em 2015, não produzirá efeitos, passando já em 2016 a se praticar as alíquotas de 60% para o Estado de origem e de 40% para o Estado de destino, conforme tabela acima.

■ 7.3.4.2.4. **Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais**

O art. 4.º da CF/88 dispõe que a República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- independência nacional;
- prevalência dos direitos humanos;
- autodeterminação dos povos;
- não intervenção;
- igualdade entre os Estados;

defesa da paz;
solução pacífica dos conflitos;
repúdio ao terrorismo e ao racismo;
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
concessão de asilo político.

■ 7.3.4.2.5. *Idioma oficial e símbolos da República Federativa do Brasil*

O **idioma oficial** da República Federativa do Brasil é a **língua portuguesa**. Daí ser o **ensino fundamental regular** ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, contudo, a possibilidade de utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (art. 13, *caput*, c/c o art. 210, § 2.º).

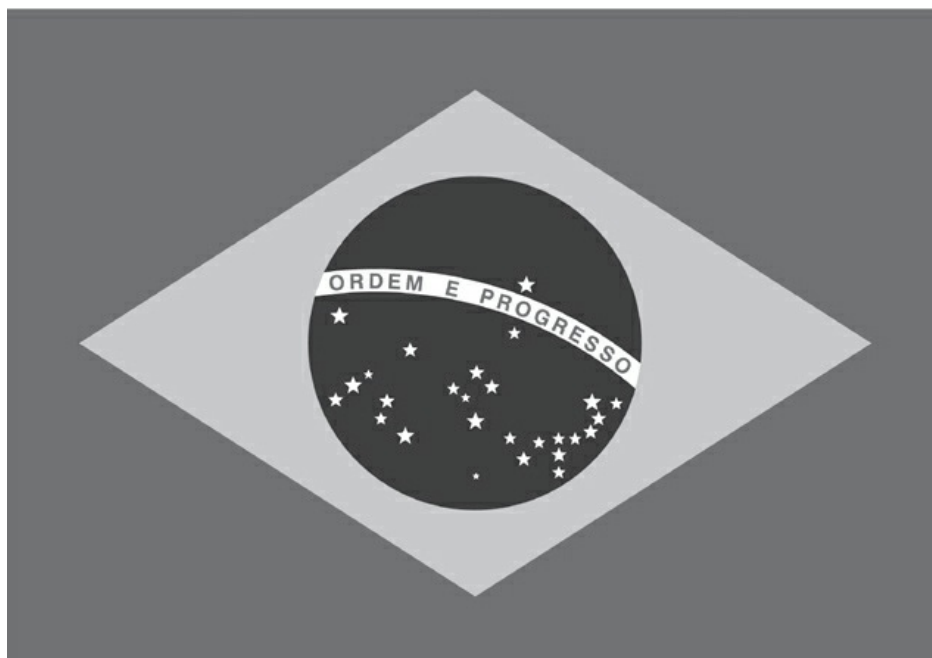
Os **símbolos** da República Federativa do Brasil são: a **bandeira**,²¹ o **hino**,²² as **armas**²³ e o **selo nacional**,²⁴ sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter os seus próprios símbolos (art. 13, §§ 1.º e 2.º).

Dentro da ideia de desenvolvimento de uma **consciência cidadã**, a Lei n. 12.472/2011 introduziu o § 6.º ao art. 32 da Lei n. 9.394/96 (*Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB*), passando a estabelecer que o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental.

Apesar de a Constituição não classificar como símbolo da República Federativa do Brasil as **cores nacionais**, a título de curiosidade, convém lembrar que a Lei n. 5.700/71, em seu art. 28, definiu, como nacionais, o **verde** e o **amarelo**, permitindo que sejam usados sem quaisquer restrições, inclusive associados a azul e branco (art. 29).

Finalmente, apenas para ilustrar, passamos a representar graficamente os símbolos da República Federativa do Brasil:²⁵

■ **Bandeira Nacional**



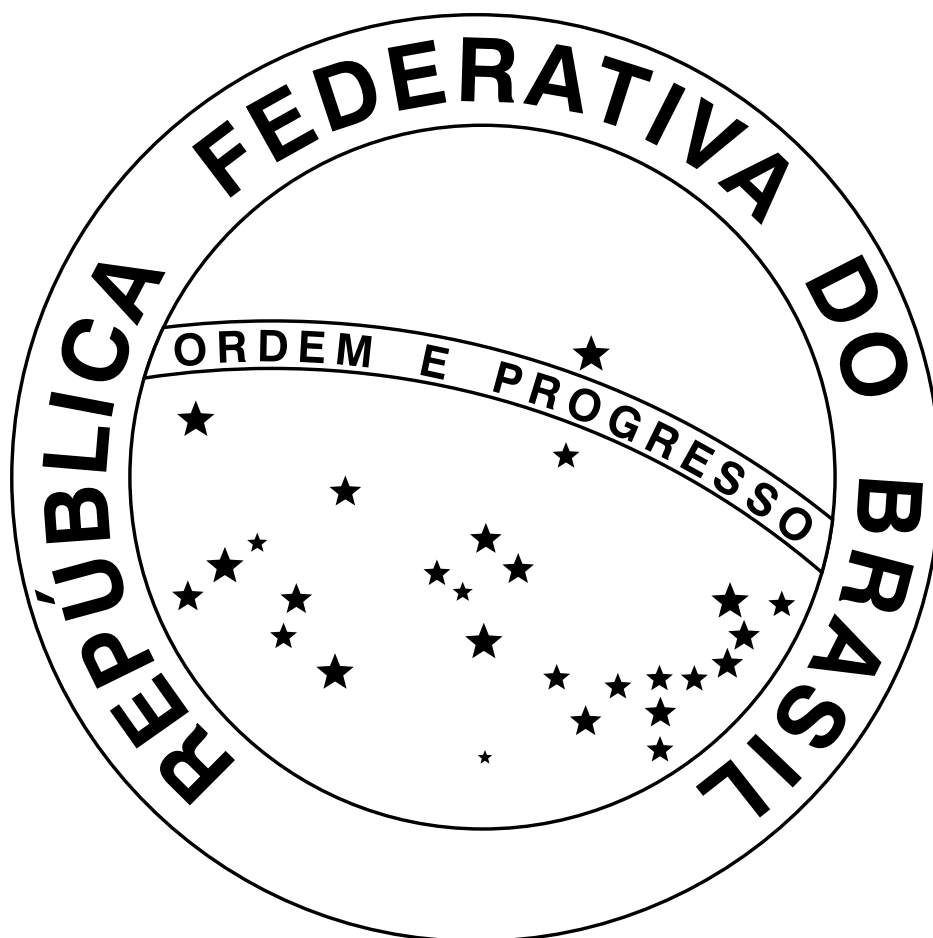
■ Hino Nacional



■ Armas Nacionais (Brasão de Armas)



■ Selo Nacional



■ 7.3.4.2.6. **Vedações constitucionais impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios**

Existe expressa vedação constitucional, prevista no art. 19 da CF/88, impossibilitando aos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios):

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. O Brasil, como veremos melhor ao analisar o art. 5.º, VI, no *item 14.10.6*, é um país **leigo, laico, não confessional**, ou seja, desde o advento da República não adota nenhuma religião oficial;

recusar fé aos documentos públicos, ou seja, os documentos públicos presumem-se idôneos (cf., também, *item 3.10.1.3*);

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, inegável desdobramento do princípio da isonomia, que será mais bem estudado no *item 14.10.2*.

■ 7.4. **UNIÃO FEDERAL**

A União Federal mais os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios compõem a República Federativa do Brasil, vale dizer, o Estado Federal, o país Brasil.

A União, segundo José Afonso da Silva, “... se constitui pela congregação das comunidades regionais que vêm a ser os Estados-membros. Então quando se fala em Federação se refere à *união* dos Estados. No caso brasileiro, seria a união dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por isso se diz *União Federal*...”.[26](#)

Assim, uma coisa é a União — unidade federativa —, ordem central, que se forma pela reunião de partes, através de um pacto federativo. Outra coisa é a República Federativa do Brasil, formada pela reunião da União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos, nos termos da CF. A

República Federativa do Brasil, portanto, é soberana no plano internacional (cf. art. 1.º, I), enquanto os entes federativos são autônomos entre si!

A União possui “**dupla personalidade**”, pois assume um papel internamente e outro internacionalmente.

Internamente, é uma pessoa jurídica de direito público interno, componente da Federação brasileira e autônoma na medida em que possui capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, configurando, assim, autonomia **financeira, administrativa e política (FAP)**.

Internacionalmente, a União representa a República Federativa do Brasil (*vide* art. 21, I a IV). Observe-se que a soberania é da República Federativa do Brasil, representada pela União Federal.

Exemplificando, de maneira interessante, David Araujo e Serrano Nunes observam: “a União age em nome de toda a Federação quando, no plano internacional, representa o País, ou, no plano interno, intervém em um Estado-membro. Outras vezes, porém, a União age por si, como nas situações em que organiza a Justiça Federal, realiza uma obra pública ou organiza o serviço público federal”.[27](#)

■ 7.4.1. Capital Federal

CONSTITUIÇÃO	DISPOSITIVO NORMATIVO	CAPITAL	LOCALIZAÇÃO
■ 1824	■ não há previsão expressa	■ Rio de Janeiro	■ cidade do Rio de Janeiro
■ Ato Adicional n. 16/1834	■ art. 1.º, 2.ª parte	■ Rio de Janeiro — elevado à condição de Município Neutro	■ cidade do Rio de Janeiro

■ 1891	■ art. 2.º	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1934	■ art. 4.º, <i>caput</i> , das Disposições Transitórias	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1937	■ art. 7.º	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1946 (primeiro momento)	■ art. 1.º, § 2.º	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1946 (segundo momento — 21.04.1960)	■ art. 4.º, ADCT	■ Distrito Federal (por força do art. 1.º, § 2.º), tendo sido dado o nome de “Brasília” à nova capital inaugurada em 21.04.1960, quando houve a sua transferência para o Planalto Central do Brasil (cf. art. 33 da Lei n. 2.874/56)	■ Planalto Central
■ 1967	■ art. 2.º	■ Distrito Federal	■ Planalto Central
■ EC n. 1/1969	■ art. 2.º	■ Distrito Federal	■ Planalto Central
■ 1988	■ art. 18, § 1.º	■ Brasília	■ Planalto Central (no território do

			Distrito Federal — RA I) 28
--	--	--	--

Brasília é a Capital Federal (art. 18, § 1.º). Trata-se de inovação em relação à Carta anterior, que estabelecia ser o Distrito Federal a Capital da União (cf. *item 7.7.1*).

Juscelino Kubitschek, cumprindo mandamento constitucional de interiorização do País (art. 3.º, CF/1891; [29](#) art. 4.º, *caput*, das Disposições Transitórias da CF/1934; [30](#) e art. 4.º, ADCT, CF/1946), [31](#) inaugurou Brasília em **21.04.1960**. [32](#)

Conforme anotou José Afonso da Silva, de acordo com as regras fixadas na Constituição de 1988, Brasília “assume uma posição jurídica específica no conceito brasileiro de ‘cidade’. Brasília é *civitas civitatum*, na medida em que é cidade-centro, polo irradiante, de onde partem, aos governados, as decisões mais graves e onde acontecem os fatos decisivos para os destinos do país. Mas **não se encaixa no conceito geral de ‘cidade’, porque não é sede de Município**. É *civitas e poli*, enquanto modo de habitar e **sede do Governo Federal**”. [33](#)

Ainda, de acordo com o art. 6.º da Lei Orgânica do DF, Brasília, além de ser a Capital da República Federativa do Brasil (e, como vimos, **sede do Governo Federal**), também é **sede do governo do Distrito Federal**.

Finalmente, o **art. 48, VII**, da CF/88 estabelece ser atribuição do Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a **transferência temporária da sede do Governo Federal**.

Veja que o texto fala em transferência **temporária** e da **sede do Governo Federal**. Assim, não se admitirá a transferência definitiva (da sede do Governo Federal) e, muito menos, a transferência da Capital Federal. Esta será **sempre** Brasília, e o que eventualmente será transferido, insista-se, será a sede do Governo Federal.

Poderíamos pensar em situações de crise, como guerra, calamidade pública ou situações que impossibilitassem o funcionamento normal do Governo

Federal, a justificar a eventual necessidade de sua transferência.

Como exemplo, citamos a **Lei n. 8.675/93**, que dispôs sobre a transferência temporária e simbólica da sede do Governo Federal para a cidade de **Salvador**, capital do Estado da Bahia, nos dias 15 e 16 de julho de 1993, datas da realização das reuniões de cúpula da *III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo*, tendo sido os atos e despachos do Presidente da República e dos Ministros de Estado datados naquela localidade. Tratava-se de homenagem prestada à cidade de Salvador que foi a primeira sede de governo do País.

■ 7.4.2. Bens da União

O art. 20 define os bens da União. Em relação a esse tema, orientamos, para as provas, uma breve leitura do referido art. 20 da CF/88 (**cuidado com a nova redação dada ao inciso IV pela EC n. 46/2005**).³⁴ Trata-se de questão sempre perguntada, exigindo a pura memorização do candidato, como se percebe nas questões selecionadas no final deste capítulo.

Tendo em vista a novidade trazida pela **EC n. 46/2005**, resolvemos destacar o art. 20, IV, da CF/88. Começamos a análise pelo quadro comparativo da redação do aludido dispositivo:

■ Art. 20, IV — as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, (AC) as áreas referidas no art. 26, II.	■ Art. 20, IV — as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II (<i>redação dada pela EC n. 46/2005</i>).
---	--

Durante a tramitação da matéria no Senado Federal, a presidência recebeu

expediente subscrito por membros da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de lideranças municipais, da sociedade civil organizada e de populares solicitando empenho para a rápida aprovação da matéria, tendo em vista a sua importância para os Municípios localizados na ilha de São Luís.

Ao analisar a antiga redação dada ao art. 20, IV, observaram: “este tratamento distinto na Constituição, dado aos municípios situados em ilhas, particularmente em ilhas costeiras, estabelece uma discriminação brutal em relação aos demais municípios brasileiros. Senão vejamos:

os moradores destes municípios, exceto aqueles residentes em terras oriundas de sesmarias, não são proprietários da área em que moram, ou têm o domínio útil, ou são posseiros;

esses mesmos moradores, excetuada a questão das sesmarias, têm que pagar IPTU às prefeituras, o que ocorre em todos os municípios brasileiros, e taxa de foros à União, fato que tecnicamente pode não ser caracterizado como bitributação, mas de fato o é, penalizando sobremaneira uma população que já possui sua capacidade de pagar impostos e taxas exaurida;

prejudica o setor primário, na medida em que o pequeno produtor, para conseguir crédito junto às agências de crédito, normalmente lhe é exigido o título de propriedade da área, que não possui;

a indústria e o comércio também são prejudicados, na medida que têm que incluir mais uma taxa em seus insumos, diminuindo sua competitividade;

o setor imobiliário é prejudicado quando, em qualquer transação de imóveis, além do ITBI, pago às prefeituras, deve ser pago laudêmio à União;

conflitos fundiários são constantes devido o entendimento da União que as terras são de sua propriedade e a existência de escrituras lavradas em cartório conferindo a terceiros estas mesmas áreas como próprias”.

No **Parecer n. 462, de 2004, da CCJC**, o relator, Senador Jorge Bornhausen, faz importante observação: “... a proposta claramente cuida apenas de restabelecer a normalidade dos fatos, retirando do patrimônio da União terras que lhe foram indevidamente atribuídas, e restituindo aos municípios tais glebas

que, em face do processo de urbanização, passaram a integrar suas respectivas áreas administrativas” (*DSF* de 12.05.2004, p. 13799).

Essa importante medida certamente estimulará o desenvolvimento local de diversos Municípios, entes federativos autônomos, podendo-se destacar, dentre tantos, três importantes Municípios que são também capitais de Estado: Florianópolis/SC, São Luís/MA e Vitória/ES. Lembramos, ainda, para se ter mais exemplos, a Ilha de Itaparica e os seus Municípios; a mágica “Morro de São Paulo”, no Município de Cairu, todas no Estado da Bahia. No Estado do Piauí destaca-se a Ilha Grande de Santa Isabel. No Estado de Santa Catarina lembramos, ainda, a Ilha de São Francisco do Sul. No Estado de São Paulo, a Ilha de São Vicente, dentre tantos outros Municípios que serão beneficiados com a medida.

A novidade trazida pela **EC n. 46/2005**, de maneira positiva, faz importante ressalva em relação às **áreas afetadas ao serviço público** e à **unidade ambiental federal**, que continuam como bens da **União**.

Finalmente, reservamo-nos a tecer brevíssimos comentários sobre alguns bens da União (apenas a definição da dimensão), cujo questionamento, pela lógica, certamente deverá aparecer em direito administrativo:

■ **mar territorial:** “... faixa de **12 milhas marítimas** de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil” (art. 1.º da Lei n. 8.617/93);

■ **zona contígua:** “... faixa que se estende das **12 às 24 milhas marítimas**, contadas das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial” (art. 4.º da Lei n. 8.617/93);

■ **zona econômica exclusiva:** “... faixa que se estende das **12 às 200 milhas marítimas**, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial” (art. 6.º da Lei n. 8.617/93);

■ **plataforma continental:** “... leito ou subsolo das áreas marítimas que se estendem **além do seu mar territorial**, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da

margem continental, **ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base**, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância” (art. 11 da Lei n. 8.617/93);

faixa de fronteira: faixa de até **150 quilômetros** de largura, ao longo das fronteiras terrestres (art. 20, § 2.º, da CF/88).

Dentro deste último conceito, convém destacar as **terras devolutas**, bens públicos *dominicais*, pertencentes à União, por força do art. 20, II, desde que situadas na *faixa de fronteira*. Logo, são bens da União as *terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei*. As demais terras devolutas, em regra, desde que não tenham sido trespassadas aos Municípios, são de propriedade dos Estados. [35](#)

■ 7.4.3. Competências da União Federal

■ 7.4.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)

A competência não legislativa, como o próprio nome ajuda a compreender, determina um campo de atuação político-administrativa, tanto é que são também denominadas competências administrativas ou materiais, pois não se trata de atividade legiferante. Regulamenta o campo do exercício das **funções governamentais**, podendo tanto ser **exclusiva** da União (marcada pela particularidade da **indelegabilidade**) como **comum** (também chamada de **cumulativa, concorrente, administrativa** ou **paralela**) aos entes federativos, assim esquematizadas:

■ **exclusiva:** art. 21 da CF/88; [36](#)

comum (cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela): art. 23 — trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Em relação à competência *comum* (cumulativa, concorrente administrativa ou

paralela), de maneira bastante interessante, o art. 23, parágrafo único, estabelece que **leis complementares** fixarão normas para a **cooperação** entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o **equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional**.

O objetivo é claro: como se trata de competência comum a todos, ou seja, concorrente no sentido de todos os entes federativos poderem atuar, o objetivo de referidas leis complementares é evitar não só conflitos como também a dispersão de recursos, procurando estabelecer mecanismos de otimização dos esforços.

Como exemplo, podemos citar a **LC n. 140/2011**, que, regulamentando os incisos III, VI e VII do art. 23 da CF/88, fixou normas para a **cooperação** entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas **ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum** relativas:

- à proteção das paisagens naturais notáveis;
- à proteção do meio ambiente;
- ao combate à poluição em qualquer de suas formas;
- à preservação das florestas, da fauna e da flora.

E se ocorrer o conflito entre os entes federativos? Nesse caso, observam Mendes, Coelho e Branco que, “se o critério da colaboração não vingar, há de se cogitar do **critério da preponderância de interesses**. Mesmo não havendo hierarquia entre os entes que compõem a Federação, pode-se falar em hierarquia de interesses, em que os mais **amplos** (da União) devem preferir aos mais restritos (dos Estados)”.³⁷

■ 7.4.3.2. *Competência legislativa*

Como a terminologia indica, trata-se de competências, constitucionalmente definidas, para **elaborar leis**. Elas foram assim definidas para a União Federal:

- **privativa**: art. 22 da CF/88. Indaga-se: apesar de ser competência privativa da União, poderiam aquelas matérias ser regulamentadas também

por outros entes federativos? Sim, de acordo com a regra do art. 22, parágrafo único, que permite à União, por meio de **lei complementar**, autorizar os **Estados** a legislar sobre questões específicas das matérias previstas no referido art. 22. Entendemos que essa possibilidade estende-se, também, ao **Distrito Federal**, por força do art. 32, § 1.º, [38](#) da CF/88. Finalmente, havendo opção política e discricionária, referida delegação não poderá ser direcionada a um único Estado determinado, mas deverá ser para todos os Estados e o DF (no exercício de sua competência estadual);

■ **concorrente:** o art. 24 define as matérias de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Em relação àquelas matérias, a competência da União limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**. Em caso de inércia da União, inexistindo lei federal elaborada pela União sobre norma geral, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, *caput*, c/c o art. 32, § 1.º) poderão suplementar a União e legislar, também, sobre as normas gerais, exercendo a **competência legislativa plena**. Se a União resolver legislar sobre norma geral, a norma geral que o Estado (ou Distrito Federal) havia elaborado terá a sua **eficácia suspensa**, no ponto em que for contrária à nova lei federal sobre norma geral. Caso não seja conflitante, passam a conviver, perfeitamente, a norma geral federal e a estadual (ou distrital). Observe-se tratar de **suspensão da eficácia, e não revogação**, pois, caso a norma geral federal que suspendeu a eficácia da norma geral estadual seja revogada por outra norma geral federal, que, por seu turno, não contrarie a norma geral feita pelo Estado, esta última voltará a produzir efeitos (lembre-se que a norma geral estadual apenas teve a sua **eficácia suspensa**); [39](#)

■ **competência tributária expressa:** art. 153 (estudar especialmente em direito tributário);

■ **competência tributária residual:** art. 154, I (instituição, mediante **lei complementar**, de impostos não previstos no art. 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na CF);

■ **competência tributária extraordinária:** art. 154, II (instituição, na iminência ou no caso de guerra externa, de **impostos extraordinários**, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão

suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação).

■ 7.4.3.3. **Competência para legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação — discussão em relação à EC n. 85/2015**

De acordo com o art. 218, *caput*, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação (cf. *item 19.6*).

Nesse sentido, a Constituição prescreve que o *Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação* será organizado em regime de **colaboração** entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

A disciplina desse sistema dar-se-á, de acordo com o art. 219-B, §§ 1.º a 2.º (EC n. 85/2015), da seguinte forma:

■ **União (lei federal):** disporá sobre as *normas gerais* do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Estados, Distrito Federal e Municípios: legislarão *concorrentemente* sobre suas peculiaridades.

Essa previsão de **competência concorrente** está também prevista no art. 24, IX (redação dada pela EC n. 85/2015).

Isso posto, indagamos: a introdução da regra contida no art. 219-B, § 2.º, CF/88, pela EC n. 85/2015, cria um novo modelo de competência concorrente na federação brasileira?

Entendemos que **não**!

Isso porque devemos analisar as atribuições destinadas aos entes federativos (União, Estados, DF e Municípios) sempre à luz do art. 24, §§ 1.º a 4.º, bem como do art. 30, I e II.

Assim, a competência da **União** limitar-se-á a estabelecer **normas gerais** sobre o *Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*. Por sua vez, a competência dos **Estados** e do **DF**, existindo a norma geral federal, destinar-se-á para complementar referida norma. A competência dos **Municípios**, por outro

lado, limitar-se-á a suplementar a legislação federal e a estadual **existentes** no que couber e sempre à luz do interesse local.

E se não existir a norma geral federal?

Nos termos do art. 24, §§ 2.º e 4.º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos **Estados** e do **DF**. Isso porque, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados e o DF exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, lembrando que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual e/ou da lei distrital, no que lhe for contrário.

Estamos propondo que essa atuação normativa **supletiva** (supletiva já que inexistente a lei federal, no caso em análise), estabelecida para os Estados e para o DF, não tenha sido estendida pela EC n. 85/2015 para os Municípios.

Muito embora no art. 219-B, § 2.º, fale-se em “legislação concorrente”, entendemos que os **Municípios** não poderão extrapolar os limites explícitos do art. 30, I e II. Em outras palavras, estão autorizados **apenas a suplementar as leis federal ou estaduais que já existem**, não podendo invadir a competência de um desses entes federativos na hipótese de inexistência das referidas leis (na medida em que a regra da competência concorrente — art. 24 — não foi introduzida para os Municípios). Havendo inércia, o parâmetro será sempre o interesse local (art. 30, I).

Vamos aguardar, então, as discussões sobre o tema, seja na doutrina, como, também, na jurisprudência do STF (**pendente** de análise futura).

■ 7.4.3.4. *Legislação sobre o meio ambiente e competência municipal. O caso particular da queima da palha da cana-de-açúcar (RE 586.224)*

As perspectivas lançadas no item anterior parecem encontrar alguma relação com precedente analisado pelo STF envolvendo a **proibição de queimada em canaviais**.

A Corte analisou a Lei n. 1.952/95, do Município de Paulínia (SP), que proibiu, **sem qualquer exceção**, a queima da palha da cana-de-açúcar.

Eis a questão: **poderia o município ter legislado sobre meio ambiente ou essa competência foi fixada apenas para a União, os Estados e o DF?**

Conforme vimos, a atribuição de proteção ao meio ambiente está fixada como matéria de competência administrativa (material) comum a todos os entes federativos (art. 23, VI). Trata-se de previsão para a atuação governamental, e não para se legislar.

A definição da competência normativa, no caso, está estabelecida como de **competência concorrente** entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, VI).

Conforme expusemos, não há previsão de aplicação das regras de competência concorrente (art. 24, §§ 1.º a 4.º) para os Municípios cuja competência foi estabelecida apenas para legislar sobre assuntos de **interesse local** (art. 30, I), podendo complementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II).

No precedente em análise, contudo, de maneira inovadora, o STF, por unanimidade, “firmou a tese de que **o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)**” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, Plenário, *DJE* de 08.05.2015).

No caso, como já existe legislação federal prevendo a eliminação planejada e gradual da queima da palha da cana-de-açúcar (art. 40 da Lei n. 12.651/2012 — Código Florestal), não poderia a lei municipal ter fixado a proibição total e imediata, especialmente por não se enquadrar a matéria como de interesse local específico daquele município.

Estamos diante de importante precedente que inova, em nosso entender, a leitura sobre o tema da competência entre os entes federativos, procurando harmonizar as regras de competência concorrente (art. 24) com aquelas de interesse local e complementar dos Municípios (art. 30, I e II).

■ 7.4.4. Regiões administrativas ou de desenvolvimento

O art. 43, *caput*, da CF estabelece que, para **efeitos administrativos**, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu **desenvolvimento** e à **redução das desigualdades regionais**.

Trata-se, nos dizeres do Professor José Afonso da Silva, de “formas especiais de organização administrativa do território”,⁴⁰ destituídas de competência legislativa, em razão de sua falta de capacidade política no âmbito jurídico-formal.

Lei complementar disporá sobre: **a)** as condições para integração de regiões em desenvolvimento; **b)** a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

Dentre os **incentivos regionais**, podemos destacar, além de outros, na forma da lei: **a)** igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; **b)** juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; **c)** isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; **d)** prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

Em relação a estas últimas áreas, sujeitas a secas periódicas, o § 3.º do art. 43 dispõe que a União incentivará a recuperação das terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação, sendo que, nos termos do art. 42 do ADCT, na redação dada pela **EC n. 43, de 15.04.2004**, durante **25 anos**, a União aplicará, do montante de recursos destinados à irrigação, 20% na Região Centro-Oeste e 50% na Região Nordeste, preferencialmente no semiárido. Trata-se, sem dúvida, da consagração do princípio das “discriminações positivas”, ou “ações afirmativas”, que será retomado no *item 14.10.2* ao tratarmos do princípio da igualdade substancial ou material (*vide*, também, arts. 3.º, III, e

187, VII).

Como exemplos de regiões administrativas ou de desenvolvimento podemos lembrar a SUDENE (LC n. 66/91), a SUDAM (LC n. 67/91), a SUFRAMA (LC n. 134/2010), as autorizações para o Poder Executivo criar as Regiões Administrativas Integradas de Desenvolvimento da Grande Teresina (LC n. 112, de 19.09.2001) e do Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA (LC n. 113, de 19.09.2001), assim como a instituição da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO —, de natureza autárquica especial, com autonomia administrativa e financeira, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e com área de atuação abrangendo os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal (LC n. 129, de 08.01.2009).

Convém destacar, contudo, tendo em vista os escandalosos, vergonhosos, indecorosos... desvios de valores de verbas públicas, a **extinção** da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), por meio, respectivamente, das **MPs ns. 2.156-5 e 2.157-5, de 24.08.2001**. Em contrapartida, foram criadas, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, as **Agências de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e da Amazônia (ADA)**, de natureza autárquica, vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de implementar políticas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia, respectivamente. Cabe apenas alertar sobre a forma de extinção da SUDAM e da SUDENE e sobre a criação da ADENE e da ADA, qual seja, por meio de medida provisória, o que poderá ser questionado perante o Judiciário, restando aguardar o pronunciamento do STF.

Posteriormente, a **LC n. 124/2007** instituiu, novamente, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM, de natureza autárquica especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, com sede na cidade de Belém, Estado do

Pará, e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

Por sua vez, a **LC n. 125/2007** instituiu, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE, também de natureza autárquica especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

■ 7.5. ESTADOS-MEMBROS

Como já verificamos ao tratar do tema *poder constituinte derivado decorrente*, os Estados federados são *autônomos*, em decorrência da capacidade de **auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação**. Trata-se de **autonomia**, e não de **soberania**, na medida em que a **soberania** é um dos **fundamentos** da República Federativa do Brasil. Internamente, os entes federativos são **autônomos**, nos limites de suas competências, constitucionalmente definidas, delimitadas e asseguradas. Constituem pessoas jurídicas de direito público interno, autônomos, nos seguintes termos:

■ **auto-organização**: art. 25, *caput*, que, como vimos, preceitua que os Estados se **organizarão** e serão **regidos** pelas leis e Constituições que adotarem, observando-se, sempre, as regras e preceitos estabelecidos na CF, conforme já expusemos ao tratar do poder constituinte derivado decorrente;

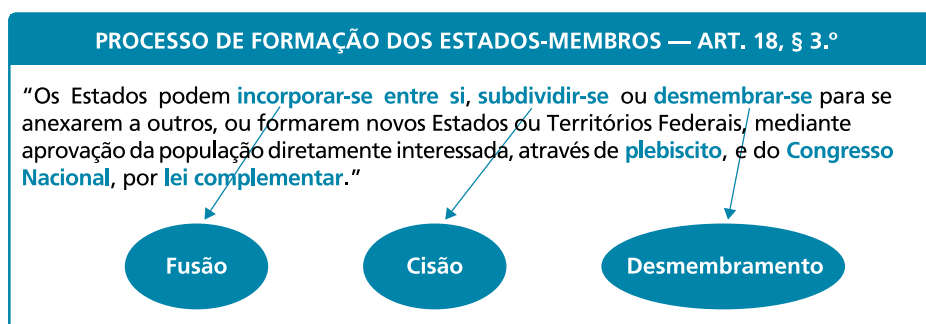
■ **autogoverno**: os arts. 27, 28 e 125 estabelecem regras para a estruturação dos “Poderes”: **Legislativo**: Assembleia Legislativa; **Executivo**: Governador do Estado; e **Judiciário**: Tribunais e Juízes (cada um dos Poderes será estudado nos *capítulos 9-11*);

■ **autoadministração e autolegislação**: arts. 18 e 25 a 28 — regras de competências legislativas e não legislativas, que serão oportunamente estudadas.

■ 7.5.1. Formação dos Estados-Membros

■ 7.5.1.1. Regra geral

O art. 18, § 3.º, da CF/88 prevê os requisitos para o processo de criação dos Estados-Membros que deverão ser conjugados com outro requisito, o do art. 48, VI. Vejamos:



■ **plebiscito:** por meio de plebiscito, a população interessada deverá aprovar a formação do novo Estado. Não havendo aprovação, nem se passará à próxima fase, na medida em que o plebiscito é **condição prévia**, **essencial** e **prejudicial** à fase seguinte;

■ **propositura do projeto de lei complementar:** o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.709/98 estabelece que, **em sendo favorável** o resultado da consulta prévia ao povo mediante plebiscito, será proposto projeto de lei perante qualquer das Casas do Congresso Nacional;

■ **audiência das Assembleias legislativas:** à Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no item anterior compete proceder a audiência das **respectivas** Assembleias Legislativas (art. 4.º, § 2.º, da Lei n. 9.709/98, regulamentando o art. 48, VI, da CF/88). Observe-se que o parecer das Assembleias Legislativas dos Estados **não é vinculativo**, ou seja, mesmo que desfavorável, poderá dar-se continuidade ao processo de formação de novos Estados (ao contrário da consulta plebiscitária, como vimos acima!);

■ **aprovação pelo Congresso Nacional:** após a manifestação das Assembleias legislativas, passa-se à fase de aprovação do projeto de **lei**

complementar, proposto no Congresso Nacional, através do *quorum* de aprovação pela **maioria absoluta**, de acordo com o art. 69 da CF/88. Cabe alertar que o Congresso Nacional não está obrigado a aprovar o projeto de lei, nem o Presidente da República está obrigado a sancioná-lo. Ou seja, ambos têm discricionariedade, mesmo diante de manifestação plebiscitária favorável, devendo avaliar a conveniência política para a República Federativa do Brasil.

■ 7.5.1.2. Aspectos específicos e procedimentais

O art. 3.º da Lei n. 9.709/98 estatui que nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3.º do art. 18 da CF (**criação de Estados-Membros**), o plebiscito e o referendo são convocados mediante **decreto legislativo**, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional.

É de observar que a competência para **autorizar** referendo e **convocar** plebiscito, de acordo com o art. 49, XV, da CF/88, é **exclusiva do Congresso Nacional**, materializada por **decreto legislativo**.

Isso posto, para responder à pergunta acima, vamos lembrar o caso concreto da proposta de divisão do **Estado do Pará**, que aconteceu em 2011 e que acabou não sendo aceita pelo povo.

O **Decreto Legislativo n. 136/2011** dispôs sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do **Carajás**,⁴¹ nos termos do inciso XV do art. 49 da Constituição Federal, enquanto, por sua vez, o **Decreto Legislativo n. 137/2011** convocou plebiscito sobre a criação do Estado do **Tapajós**.⁴²

Interessante notar que foram os parlamentares os responsáveis pela definição do suposto novo desenho do atual Estado do Pará no caso de aprovação do plebiscito.

Ou seja, essa definição já chega pronta para que a população do Estado responda no momento da consulta.

A) E quais poderiam ser os possíveis resultados do plebiscito?

Conforme sinalizado anteriormente, se o povo responder que não é a favor da separação para formação de novos Estados (**desmembramento formação**), o procedimento não seguirá, ou seja, a **vontade negativa** do povo **vincula**, não podendo, assim, jamais, o Parlamento aprovar eventual projeto de lei complementar criando os novos Estados contra a vontade negativa manifestada no plebiscito.

Portanto, parece-nos possível concluir que a **democracia direta prevalece sobre a democracia representativa**.

Agora, ao invés, se a **vontade** do povo for no **sentido favorável**, o projeto de lei complementar poderá seguir a sua tramitação e, assim, o parlamento, **com autonomia**, avaliará a conveniência ou não da criação dos novos Estados.

Isso significa que o Congresso Nacional terá total liberdade para não aceitar a criação dos novos Estados, até porque é o órgão político responsável pela avaliação e conveniência do novo desenho do Estado brasileiro.

B) Se a população autorizar o procedimento e o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei complementar, o Presidente da República poderá vetar o projeto de lei?

Sim! O que quer dizer que o Presidente da República terá autonomia para ir contra a vontade do povo. E, novamente, essa situação não tem nenhum empecilho, na medida em que o Chefe do Executivo, mesmo que eleito pelo povo, tem, em igual sentido, liberdade para avaliar a conveniência do novo “desenho”.

Nesse caso, parece-nos que, consagrando o **sistema dos freios e contrapesos** e em respeito à literalidade do **art. 66, § 4.º, da CF/88**, necessariamente, o veto presidencial será apreciado pelo Parlamento em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, podendo ser **rejeitado** pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores (lembramos que, para essa hipótese, a **EC n. 76/2013**, no tocante ao modo de votação, aboliu a regra do escrutínio secreto, passando a ser votação ostensiva, ou seja, voto “aberto”).

Avançando, o art. 18, § 3.º, da CF/88 estabelece que os Estados podem desmembrar-se para formar novos Estados mediante **aprovação da população**

diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

C) O que deve ser entendido por população diretamente interessada a ser ouvida no plebiscito?

Em **24.08.2011**, o Plenário do STF decidiu, no julgamento da **ADI 2.650**,⁴³ que o plebiscito para o desmembramento de um Estado da Federação deve envolver não somente a população do território a ser desmembrado mas também a de **todo o Estado-Membro**, no caso do exemplo em análise, a população de todo o Estado do Pará.

E como fica o resto do Brasil? Será que a mudança no desenho da Federação não afetaria o interesse das populações e dos outros Estados?

Essa preocupação foi manifestada pelo Min. Marco Aurélio no julgamento da referida ADI 2.650, que chegou a afirmar a necessidade de se fazer a consulta envolvendo a população de todo o território nacional.

Conforme noticiado, explicou “... que os estados e os municípios de hoje têm participação em receitas federais e estaduais. ‘Ora, se há possibilidade de vir à balha um novo município ou um novo estado haverá prejuízo para as populações dos demais estados e dos demais municípios, e a razão é muito simples: aumentará o divisor do fundo alusivo aos estados e do fundo também referente aos municípios’” (*Notícias STF*, 24.08.2011).

Contudo, como visto, **essa tese não prevaleceu**.

Assim, muito cuidado e retomando: população diretamente interessada deve ser entendida como **a população de todo o Estado-Membro (ou de todo o Município, no caso de seu desmembramento), e não apenas a população da área a ser desmembrada**.

Em relação ao **resto do Brasil**, podemos afirmar que a consulta acabará sendo realizada, segundo anotado no julgamento da ADI 2.650, **indiretamente**, por meio dos seus **representantes eleitos**, na medida em que, relembramos, o Congresso Nacional terá discricionariedade para aprovar ou não o projeto de LC, mesmo diante de plebiscito favorável.

■ 7.5.1.3. *E qual deve ser o procedimento no caso de criação de um novo Estado?*

Ou, em outras palavras, o que acontecerá se o povo autorizar a criação do novo Estado, o projeto de lei complementar for aprovado pelo Congresso Nacional e o Presidente da República sancioná-lo, promulgando e determinando a publicação da nova lei, que efetivamente tratará do novo desenho do território nacional?

Nesse caso, de acordo com o **art. 235** da CF/88, nos **10 primeiros anos** da referida criação, serão observadas as seguintes regras básicas:

- a Assembleia Legislativa será composta de 17 Deputados, se a população do Estado for inferior a 600.000 habitantes, e de 24, se igual ou superior a esse número, até 1.500.000;

- o Governo terá no máximo 10 Secretarias;

- o Tribunal de Contas terá 3 membros, nomeados pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber;

- o Tribunal de Justiça terá 7 Desembargadores;

- os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhidos na forma do art. 235, V, “a” e “b”;

- no caso de Estado proveniente de Território Federal, os 5 primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do País;

- em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público de provas e títulos;

- até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com 35 anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis *ad nutum*;

- se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal ocorrerá de acordo com o art. 235, IX, “a” e “b”;

as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados, serão disciplinadas na Constituição Estadual;

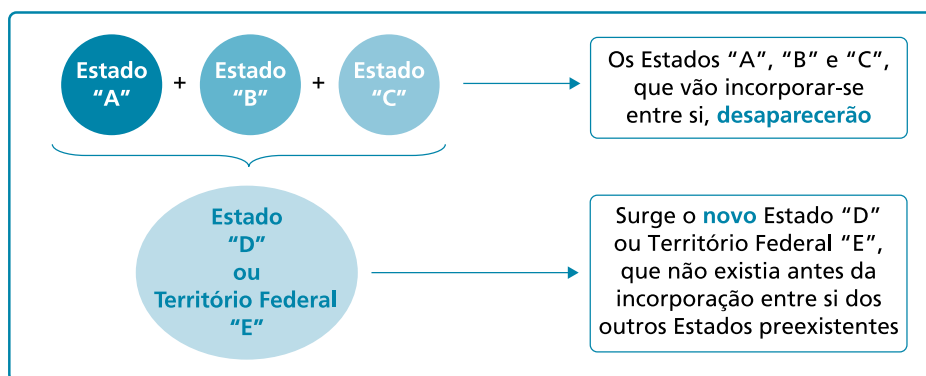
as despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado.

■ 7.5.1.4. Fusão

O art. 18, § 3.º, determina que os Estados poderão **incorporar-se entre si**. Trata-se do instituto da **fusão**, na medida em que dois ou mais Estados se unem geograficamente, formando um terceiro e novo **Estado** ou **Território Federal**, distinto dos Estados anteriores, os quais, por sua vez, perderão a personalidade primitiva. Ou seja, os Estados que se incorporarem entre si não mais existirão; o Estado ou Território Federal que será formado considera-se inexistente antes do processo de fusão.

Nesse caso, por população diretamente interessada, a ser consultada mediante plebiscito, deve-se entender a população de cada um dos Estados que desejam fundir-se.

Como exemplo, podemos lembrar o art. 8.º da **LC n. 20/74**, que criou o atual **Estado do Rio de Janeiro** em razão da fusão dos *Estados do Rio de Janeiro* e da *Guanabara* (antigo Município Neutro, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro e que foi a capital do Brasil, transformada em Distrito Federal pela Constituição de 1891, e transformado no Estado da Guanabara em 21.04.1960 quando houve a inauguração de Brasília e a transferência da Capital para o Planalto Central).

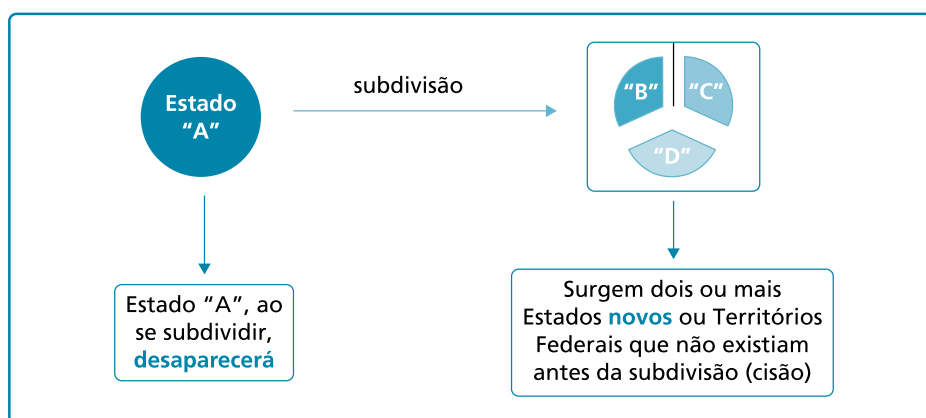


■ 7.5.1.5. *Cisão*

A **cisão** ocorre quando um Estado que já existe **subdivide-se**, formando dois ou mais Estados-Membros novos (que não existiam), com personalidades distintas, ou Territórios Federais. O Estado originário que se subdividiu **desaparece**, deixando de existir politicamente.

Como anota José Afonso da Silva, subdivisão “... significa separar um todo em várias partes, formando cada qual uma unidade independente das demais”.⁴⁴

Por população diretamente interessada a ser consultada, mediante plebiscito, sobre a subdivisão do Estado deve-se entender a população do referido Estado que vai partir-se.



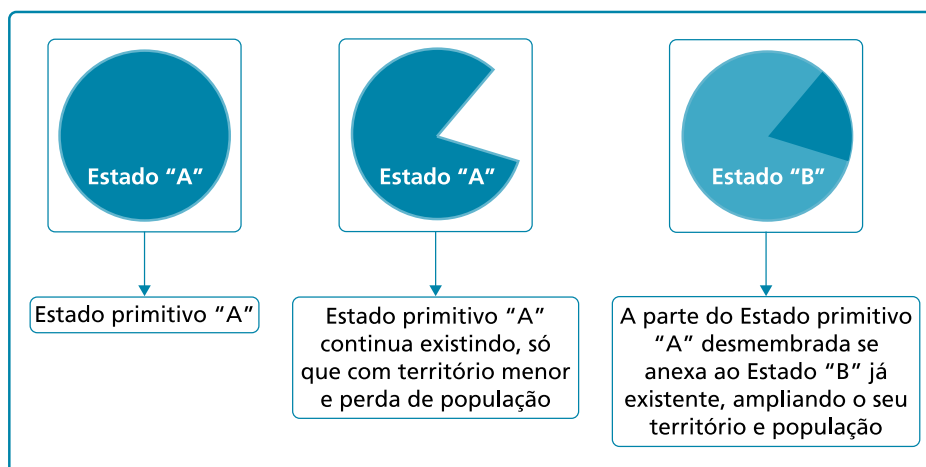
■ 7.5.1.6. *Desmembramento*

Ao estabelecer o art. 18, § 3.º, que os Estados podem **desmembrar-se**, fixou-se a possibilidade de um ou mais Estados cederem parte de seu território geográfico para formar um novo Estado ou Território Federal que não existia ou se anexar (a parte desmembrada) a um outro Estado que já existia.

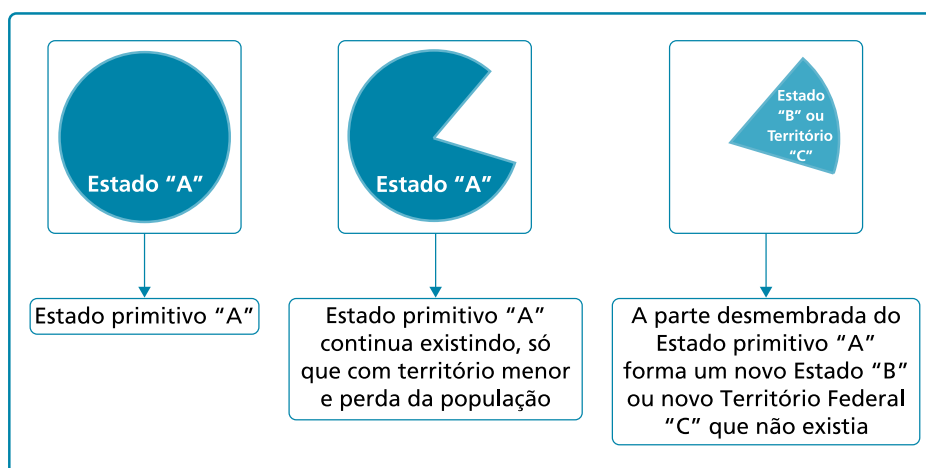
Como regra, **o Estado originário não desaparece**. Foi o que aconteceu com o Estado de Goiás em relação ao do **Tocantins** (art. 13 do ADCT) e com o do Mato Grosso em relação a Mato Grosso do Sul, este criado pela LC n. 31/77.

Assim, surgem duas modalidades de desmembramento:

■ **desmembramento anexação** — a parte desmembrada vai anexar-se a um Estado que já existe, ampliando o seu território geográfico. Não haverá criação de um novo Estado. Tanto o Estado primitivo permanece (só que com área e população menores) como o Estado que receberá a parte desmembrada continua a existir (só que com área e população maiores);



■ **desmembramento formação** — a parte desmembrada se transformará em um ou mais de um Estado novo ou Território Federal, que não existia.



Reforçando, nos dois casos o Estado originário **não** desaparecerá, não ocorrendo a perda de sua identidade. Apenas perderá parte de seu território e da população.

No tocante ao plebiscito, por população diretamente interessada deve ser entendida tanto a do território que se pretende desmembrar como a que receberá o acréscimo, na hipótese de desmembramento anexação. Na hipótese de

desmembramento formação deve ser ouvida a população do Estado que sofrerá o desmembramento.

■ 7.5.2. Bens dos Estados-Membros

De acordo com o art. 26 da CF/88, incluem-se entre os bens dos Estados: I — as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; II — as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; III — as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; IV — as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

■ 7.5.3. Competências dos Estados-Membros

■ 7.5.3.1. *Competência não legislativa (administrativa ou material)*

■ **comum** (**cumulativa, concorrente, administrativa** ou **paralela**): trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23 da CF/88;

■ **residual (remanescente ou reservada)**: são reservadas aos Estados as competências administrativas que não lhes sejam vedadas, ou a competência que sobrar (eventual resíduo), após a enumeração dos outros entes federativos (art. 25, § 1.º), ou seja, as competências que não sejam da União (art. 21), do Distrito Federal (art. 23), dos Municípios (art. 30, III a IX) e comum (art. 23).

■ 7.5.3.2. *Competência legislativa*

Como a terminologia indica, trata-se de competências, constitucionalmente

definidas, **para elaborar leis**. Foram assim definidas para os Estados-Membros:

■ **expressa**: art. 25, *caput* qual seja, como vimos, a capacidade de auto-organização dos Estados-Membros, que se regerão pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da CF/88;

■ **residual (remanescente ou reservada)**: art. 25, § 1.º toda competência que não for vedada está reservada aos Estados-Membros, ou seja, o resíduo que sobrar, o que não for de competência expressa dos outros entes e não houver vedação, caberá aos Estados materializar;

■ **delegada pela União**: art. 22, parágrafo único como vimos, a União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência privativa prevista no art. 22 e incisos. Tal autorização dar-se-á por meio de **lei complementar**; [45](#)

■ **concorrente**: art. 24 a concorrência para legislar dar-se-á entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à **União** legislar sobre normas gerais e aos **Estados**, sobre normas específicas;

■ **suplementar**: art. 24, §§ 1.º a 4.º no âmbito da legislação concorrente, como vimos, a União limita-se a estabelecer normas gerais e os Estados, normas específicas. No entanto, em caso de inércia legislativa da União, os Estados poderão **suplementá-la**, regulamentando as regras gerais sobre o assunto, sendo que, na superveniência de lei federal sobre norma geral, a aludida norma estadual geral (suplementar) terá a sua eficácia suspensa, no que for contrária à lei federal sobre normas gerais editadas posteriormente. [46](#) Assim, poderíamos, conforme a doutrina, dividir a competência suplementar em duas, a saber: **a) competência suplementar complementar** — na hipótese de já existir lei federal sobre a matéria, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal (na competência estadual) simplesmente completá-las; **b) competência suplementar supletiva** — nessa hipótese inexistente a lei federal, passando os Estados e o Distrito Federal (na competência estadual), temporariamente, a ter a competência plena sobre a matéria;

■ **tributária expressa**: art. 155 (estudar especialmente em direito tributário).

■ 7.5.4. Exploração dos serviços locais de gás canalizado

Os **serviços locais de gás canalizado** serão explorados diretamente pelos Estados, ou mediante concessão, na forma da lei, vedando-se a regulamentação da referida matéria por medida provisória, como expressamente previsto no art. 25, § 2.º (com a redação determinada pela EC n. 5/95), e em decorrência do art. 246 da CF/88.

A Lei n. 9.478, de 06.08.1997 (*vide* também a Lei n. 9.847, de 26.10.1999), veio dispor sobre a **política energética nacional** e as **atividades relativas ao monopólio do petróleo**, instituindo o **Conselho Nacional de Política Energética** e a **Agência Nacional do Petróleo**, além de outras providências pertinentes à matéria.

Trata-se, de acordo com o art. 6.º, XXII, da aludida lei, da **distribuição de gás canalizado**, ou seja, serviços locais de comercialização de gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2.º do art. 25 da CF.[47](#)

■ 7.5.5. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

■ 7.5.5.1. Aspectos gerais

A política de agrupamento de municípios para a implementação de *serviços públicos comuns*, como, por exemplo, os de saneamento básico, foi **lançada** na Constituição de 1937 (art. 29), que delegava aos Estados a regulamentação das condições, bem como a forma de sua administração.

A Constituição de 1946 permitiu ao Estado apenas a criação de órgão de assistência técnica aos Municípios.

Já a de 1967 (art. 157, § 10) e a EC n. 1/69 (art. 164) trataram de modo explícito da possibilidade de criação de *regiões metropolitanas*, para a realização de *serviços de interesse comum*, mediante lei complementar do Congresso Nacional, ou seja, a competência era da União.

A Constituição de 1988, por sua vez, inovando, passa a atribuir aos **Estados** a competência para instituir não só as **regiões metropolitanas** mas, também, **aglomerações urbanas** e **microrregiões**, nos seguintes termos (art. 25, § 3.º):

- **legitimados:** Estados-Membros;
- **requisito formal:** a instituição dar-se-á por **lei complementar** a ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado;
- **requisito material (elementos de constituição):** agrupamento de municípios limítrofes (dois ou mais);
- **finalidade:** integrar a organização, o planeamento e a execução de **funções públicas de interesse comum**. Segundo interpretou o STF, “o interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais” (**ADI 1.842**, j. 06.03.2013);
- **função pública de interesse comum:** “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (art. 2.º, II, da Lei n. 13.089/2015 — “Estatuto da Metrópole”).

■ 7.5.5.2. *Conceito*

De acordo com José Afonso da Silva:[48](#)

- **região metropolitana:** “constitui-se de um conjunto de Municípios cujas sedes se unem com certa continuidade urbana em torno de um Município-polo”;
- **microrregiões:** “formam-se de grupos de Municípios limítrofes com certa homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas por continuidade urbana”;
- aglomerados urbanos:** “carecem de conceituação, mas, de logo, se percebe que se trata de áreas urbanas, sem um polo de atração urbana,

quer tais áreas sejam das cidades sedes dos Municípios, como na baixada santista (em São Paulo), ou não”.

Para o ilustre professor, o que dá essência ao conceito de **região metropolitana**, legitimando-a e justificando-a, é o fenômeno da **conurbação**, ou seja, “a existência de núcleos urbanos contíguos, contínuos ou não, subordinados a mais de um Município, sob a **influência de um Município-polo**”.

As *microrregiões* distinguem-se das *regiões metropolitanas* sob esse aspecto fático, caracterizando-se como “regiões espaciais definidas para *finals administrativos*, que também pressupõem a existência de um agrupamento de Municípios limítrofes com interesses comuns”, mas sem o citado aspecto urbanístico (a *conurbação*, “realidade fática, antológica, essência conceitual”).

A **região metropolitana**, diferente da *microrregião* (definida para fins administrativos), apresenta-se, portanto, como **região urbana** (“comunidade integrada em um espaço fortemente urbanizado”), e não puramente territorial. Essa característica marcante também se verifica nos *aglomerados urbanos*, que, contudo, diferente das *regiões metropolitanas*, não possuem um polo de atração urbana. [49](#)

Partindo dessa perspectiva doutrinária, devemos destacar as definições contidas no *Estatuto da Metrópole* (Lei n. 13.089/2015), a saber:

■ **região metropolitana:** “aglomeração urbana que configure uma **metrópole**”, definida como o “espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem **influência nacional** ou sobre uma região que configure, no mínimo, a **área de influência de uma capital regional**, conforme os critérios adotados pelo IBGE, que deverão levar em consideração os bens e serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, empregos e outros itens pertinentes, disponibilizados pela referida fundação na rede mundial de computadores”;

aglomeração urbana: “unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por

complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas”.

De maneira bastante interessante, o art. 4.º do *Estatuto da Metrópole* prevê a possibilidade de instituição de **região metropolitana** ou de **aglomeração urbana** que envolva **Municípios pertencentes a mais de um Estado**, hipótese em que será formalizada mediante a aprovação de **leis complementares pelas assembleias legislativas de cada um dos Estados envolvidos**.

Até a aprovação das referidas leis complementares por todos os Estados, a região metropolitana ou a aglomeração urbana terá validade apenas para os Municípios dos Estados que já houverem aprovado a respectiva lei.

■ 7.5.5.3. O que aconteceu com as regiões metropolitanas instituídas antes da nova Constituição de 1988?

Conforme se observou, a partir de 1988, a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões passou a depender de **lei complementar estadual**.

No ordenamento jurídico anterior, a competência era da União, destacando-se os seguintes exemplos, **recepcionados** e que perduram até que lei complementar estadual disponha de modo diverso:

■ **LC n. 14/73**: regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza;

■ **LC n. 20/74**: região metropolitana do Rio de Janeiro, que veio a ser alterada pela **LC estadual n. 87/97**.

■ 7.5.5.4. Caráter compulsório da participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

O art. 357, parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro exigia a *prévia aprovação pela respectiva câmara municipal* para a participação de qualquer município em região metropolitana.

O STF, interpretando o art. 25, § 3.º, reconheceu o **caráter compulsório da participação**, bastando a existência de **lei complementar estadual** (ADI 1.841, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 1.º.08.2002, Plenário, DJ de 20.09.2002).

Em igual sentido já havia decidido a Corte em relação ao art. 216, § 1.º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, declarando **inconstitucional** a *exigência de plebiscito às populações diretamente interessadas* para a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Como se disse, basta a existência de lei complementar aprovada pela Assembleia Legislativa estadual (ADI 796, j. 02.02.1998).

O tema voltou a ser reafirmado no julgamento da ADI 1.842 (j. 06.03.2013), também envolvendo lei complementar específica estadual que criou a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos.

Conforme ficou estabelecido, “a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do **saneamento básico**, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que **este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal**” (*item 4 da ementa*).

■ **7.5.5.5. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal que deverá ser preservada. Não se admite a simples transferência de competências exclusivamente para o Estado-Membro. A gestão deverá ser compartilhada**

Analisando o caso concreto do Estado do Rio de Janeiro, o STF deixou claro que a **autonomia municipal** deverá ser preservada. Assim, a organização, o planejamento e a execução de *funções públicas de interesse comum*, bem como o seu processo decisório, não poderão ser transferidos com exclusividade para o Estado-Membro, devendo ser assegurada a participação tanto dos municípios compreendidos como do referido ente federativo.

Conforme ficou assentado na *ementa* do julgamento da **ADI 1.842**, “o interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região”.

Dessa forma, “o parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre Municípios e Estado. **É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios**”.

Ao final, a Corte estabeleceu que “a **participação** dos entes nesse colegiado **não necessita de ser paritária**, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, **sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto**”.

■ 7.5.5.6. “Estatuto da Metrópole” — Lei n. 13.089/2015

Em discussão desde o advento do “Estatuto da Cidade” (Lei n. 10.257/2001), em sua complementação, a União elaborou a **Lei n. 13.089, de 12.01.2015**, instituindo o denominado “**Estatuto da Metrópole**”.

Tendo por fundamento os arts. 21, XX; 23, IX; 24, I; 25, § 3.º e 182, o *Estatuto da Metrópole* estabelece:

diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em **regiões metropolitanas** e em **aglomerações urbanas** instituídas pelos Estados;

normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa;

critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

Além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, as disposições introduzidas na lei aplicam-se, no que couber, às **microrregiões** instituídas pelos Estados com fundamento em **funções públicas de interesse comum com características predominantemente urbanas**.

De modo bastante interessante, o *Estatuto da Metrópole* preserva o entendimento firmado pelo STF no julgamento da **ADI 1.842** (cf. *item 7.5.5.4*), confirmando o caráter compulsório de participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões, com a preservação da autonomia dos entes federativos em relação aos interesses comuns de abrangência metropolitana, como os serviços de transporte público, saneamento básico, meio ambiente, mobilidade urbana, moradia etc.

Lança-se a ideia de uma denominada **“governança interfederativa”**, definida pelo estatuto como o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum” (art. 2.º, IV).

Por sua vez, o art. 6.º da referida Lei n. 13.089/2015 estabelece que a **governança interfederativa** das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, com a previsão expressa de apoio da União, respeitará os seguintes **princípios**:

- prevalência do interesse comum sobre o local;
- compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;
- autonomia dos entes da Federação;
- observância das peculiaridades regionais e locais;
- gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei n. 10.257/2001;
- efetividade no uso dos recursos públicos;
- busca do desenvolvimento sustentável.

No fundo, o estatuto confirma uma inegável tendência e realidade dos tempos atuais, marcada por não mais se sustentar a plena e isolada autonomia municipal, nem a crença em uma ultrapassada onipresença do Estado para tratar das

questões supramunicipais.

O que se tem é a confirmação da necessidade de participação de todos os entes federativos envolvidos, bem como o necessário e permanente diálogo no tocante à organização, ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum.

■ **7.5.5.7. Qual a natureza jurídica das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões criadas por lei complementar estadual?**

Apesar da discussão doutrinária sobre o assunto, Michel Temer estabelece que a região metropolitana (e em seguida diz caber tal observação para as aglomerações urbanas e microrregiões) “não é dotada de personalidade. Com este dizer fica afastada a ideia de governo próprio ou, mesmo, de administração própria. Não é pessoa política nem administrativa. Não é centro personalizado. Não é organismo. É órgão”. [50](#)

Em outras palavras, instituído o agrupamento de municípios por um dos instrumentos, **não se criará um novo ente federativo**, não se tratará de entidade política autônoma, mas, em essência, será estabelecido um órgão com função meramente administrativa e executória, nos termos da lei complementar estadual.

Alaor Caffé Alves vislumbra no permissivo do art. 25, § 3.º, a possibilidade de se instituir uma “nova forma de administração regional, no âmbito dos Estados, como um corpo-administrativo territorial (**autarquia territorial, intergovernamental e plurifuncional**), sem personalidade *política*”. [51](#)

Essa *entidade regional* criada para a implementação das *funções públicas de interesse comum*, sempre assegurando a participação dos Municípios e do Estado, não poderá se confundir com as pessoas *políticas* que a instituirão, mas, naturalmente, poderá, diante da transferência de parte específica de competências e atribuições previstas na Constituição, ter personalidade *jurídica* (não política!).

Nesse sentido, interessante anotar o reconhecimento, pelo Min. Gilmar Mendes, de se implementar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum por **agências reguladoras**.

Ao analisar o caso concreto do Estado do Rio de Janeiro (**ADI 1.842**), em seu voto, reconheceu que o **serviço de saneamento básico** “— no âmbito de regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos — constitui interesse coletivo que não pode estar subordinado à direção de único ente, mas deve ser planejado e executado de acordo com decisões colegiadas em que participem tanto os municípios compreendidos como o estado federado”.

“Portanto, nesses casos, o poder concedente do serviço de saneamento básico nem permanece fracionado entre os municípios, nem é transferido para o estado federado, mas deve ser dirigido por **estrutura colegiada** — instituída por meio da lei complementar estadual que cria o agrupamento de comunidades locais — em que a vontade de um único ente não seja imposta a todos os demais entes políticos participantes. Esta estrutura colegiada deve regular o serviço de saneamento básico de forma a dar viabilidade técnica e econômica ao adequado atendimento do interesse coletivo.”

E concluiu: “... a mencionada estrutura colegiada pode ser implementada tanto por **acordo**, mediante **convênios**, quanto de **forma vinculada**, na instituição dos agrupamentos de municípios. Ademais, a instituição de **agências reguladoras** pode se provar como forma bastante eficiente de estabelecer padrão técnico na prestação e concessão coletivas do serviço de saneamento básico” (original sem grifos).

■ 7.6. MUNICÍPIOS

O Município pode ser definido como pessoa jurídica de direito público interno e **autônoma** nos termos e de acordo com as regras estabelecidas na CF/88.

Muito se questionou a respeito de serem os Municípios parte integrante ou não de nossa Federação, bem como sobre a sua autonomia. A análise dos arts. 1.º e 18, bem como de todo o capítulo reservado aos Municípios (apesar de

vozes em contrário), leva-nos ao único entendimento de que eles são entes federativos, dotados de autonomia própria, materializada por sua capacidade de **auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação**. Ainda mais diante do art. 34, VII, “c”, que prevê a intervenção federal na hipótese de o Estado não respeitar a **autonomia municipal**.

Como já alertamos, trata-se de **autonomia**, e não de **soberania**, uma vez que a **soberania** é um dos **fundamentos** da República Federativa do Brasil. Internamente, os entes federativos são **autônomos**, na medida de sua competência, constitucionalmente definida, delimitada e assegurada. Vejamos:

■ **auto-organização:** art. 29, *caput* — os Municípios organizam-se por meio de **Lei Orgânica**, votada em **dois turnos**, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por **dois terços** dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e o preceituado nos incisos I a XIV do art. 29 da CF/88;

■ **autogoverno:** elege, diretamente, o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores (confira incisos do art. 29);

■ **autoadministração e autolegislação:** art. 30 — regras de competência que serão oportunamente estudadas. O STF, ao destacar a essência da autonomia municipal, estabeleceu que a autoadministração implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica (ADI 1.842, *item 3 da ementa*).

■ 7.6.1. Formação dos Municípios

O art. 18, § 4.º, da CF/88, com a redação dada pela EC n. 15/96, fixa as regras para a **criação, incorporação, fusão e desmembramento** de Municípios, nos seguintes termos e obedecendo às seguintes etapas:

■ **lei complementar federal:** determinará o período para a mencionada criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios, bem

como o procedimento;⁵²

■ **estudo de viabilidade municipal:** deverá ser apresentado, publicado e divulgado, na forma da lei, estudo demonstrando a viabilidade da criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios;

■ **plebiscito:** desde que positivo o estudo de viabilidade, far-se-á consulta às populações dos Municípios envolvidos (de todos os Municípios envolvidos, e não apenas da área a ser desmembrada, como vimos em relação aos Estados-Membros), para aprovarem ou não a criação, incorporação, fusão ou desmembramento. Referido **plebiscito** será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual (art. 5.º da Lei n. 9.709/98);

lei estadual: dentro do período que a lei complementar federal definir, desde que já tenha havido um estudo de viabilidade e aprovação plebiscitária, serão criados, incorporados, fundidos ou desmembrados Municípios, através de **lei estadual**.

Portanto, o **plebiscito** é **condição de procedibilidade** para o processo legislativo da lei estadual. Se favorável, o legislador estadual terá discricionariedade para aprovar ou rejeitar o projeto de lei de criação do novo Município. Em igual sentido, mesmo que aprovada a lei pelo legislador estadual, o Governador de Estado poderá vetá-la.

Modificando anterior jurisprudência do TSE (*MS 1.511/DF, de 05.06.1992*), o art. 7.º da Lei n. 9.709/98 dispõe que a consulta plebiscitária deverá ocorrer perante as **populações diretamente interessadas**, tanto a do território que será desmembrado como a do distrito que pretende desmembrar-se.

Finalmente, destacamos o julgamento da **ADI 2.240**, na qual se discutiram as regras do art. 18, § 4.º, especialmente a **necessidade de LC federal** determinando o período de criação de novos Municípios.

REDAÇÃO ORIGINAL (1988)	REDAÇÃO DADA PELA EC N. 15/96
■ Art. 18, § 4.º: A criação, a	■ Art. 18, § 4.º: A criação, a incorporação,

incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano , far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual , e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.	■ Art. 18, § 4.º: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal , e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
---	--

Pelo que se percebe da leitura comparativa do texto do art. 18, § 4.º, a **EC n. 15/96** estabeleceu outros requisitos para a criação de novos Municípios, dificultando-a. Essa, por sinal, era a intenção do constituinte reformador, buscando evitar o surgimento desenfreado de novos Municípios e sob o controle exclusivo (na redação original) da *LC estadual*.

Aliás, como já estudamos no *item 6.7.1.9*, nessa linha, entendeu o STF que o art. 18, § 4.º, na redação trazida pela EC n. 15/96, é **norma de eficácia limitada** e, por isso, toda lei estadual que criar Município sem a existência da lei complementar federal estará eivada de inconstitucionalidade. Trata-se de **vício formal por violação a um dos pressupostos objetivos do ato**.⁵³

Por isso, reconhecendo a *inertia deliberandi* do Congresso Nacional em apreciar os vários projetos de LC que tramitavam (e vejam que, à época do julgamento, já se fazia mais de 15 anos que a regra havia sido estabelecida pela EC n. 15/96), no julgamento da **ADO 3.682**, o STF, fazendo um **apelo** ao legislador, fixou o prazo de 18 meses para que o art. 18, § 4.º, da CF/88 fosse regulamentado (*vide item 6.7.4.9*).

Por consequência, nas várias ADIs julgadas,⁵⁴ o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que criaram Municípios sem a existência da LC federal, mas não pronunciou a nulidade dos atos, mantendo a vigência

Buscando regularizar a situação de vários Municípios, o Congresso Nacional promulgou a **EC n. 57, de 18.12.2008**, acrescentando o **art. 96 ao ADCT**, com a seguinte redação: “ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação”.

Chegamos a fazer críticas firmes à nova emenda, em nosso entender, não apenas **inconstitucional** como, acima de tudo, **imoral**.

Todavia, em determinado caso concreto, o STF acabou aceitando os seus termos:

“EMENTA: Criação do Município de Pinto Bandeira/RS. **Ação julgada prejudicada pela edição superveniente da EC 57/2008**. Alegação de contrariedade à EC 15/96 (...). Com o advento da EC 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. A Lei 11.375/99 foi publicada nos termos do art. 9.º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela EC 20/97, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada” (**ADI 2.381-AgR**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.2011, Plenário, *DJE* de 11.04.2011).

Apesar desse precedente, devemos alertar que não se extinguiu a necessidade da existência de **lei complementar federal** que regularize o processo de formação dos Municípios. A referida emenda apenas “validou” a criação (inconstitucional — e aí a nossa crítica) dos novos Municípios estabelecidos sem a existência da referida LC federal.

Por esse motivo, não há dúvida de que se eventual Município vier a ser criado após 31.12.2006 e ainda não tiver sido editada a LC federal prevista no art. 18, § 4.º, também estaremos diante de vício formal de inconstitucionalidade (esse, aliás, tem sido o entendimento do STF: cf. **ADI 4.992**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.09.2014, Plenário, *DJE* de 13.11.2014).

Finalmente, devemos deixar anotado que, apesar de o Congresso Nacional ter aprovado em mais de uma oportunidade projetos de leis complementares

disciplinando a matéria, estes foram vetados pela Presidente da República Dilma Rousseff. O último, nos mesmos termos de veto anterior, de acordo com a Mensagem n. 250/2014, teve por fundamento o dito **interesse público**: “depreende-se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que haja a correspondente geração de novas receitas”.

■ 7.6.2. Competências dos Municípios

■ 7.6.2.1. Competências não legislativas (*administrativas ou materiais*)

■ **comum** (**cumulativa, concorrente, administrativa** ou **paralela**): trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23 da CF/88;

■ **privativa (enumerada)**: art. 30, III a IX — assim definida: “Art. 30. Compete aos Municípios: ... III — instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV — criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; VI — manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental (redação dada pela EC n. 53/2006); VII — prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII — promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX — promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”.

■ 7.6.2.2. Competências legislativas

■ 7.6.2.2. Competências legislativas

■ **expressa:** art. 29, *caput* — qual seja, como vimos, a capacidade de auto-organização dos Municípios, através de **lei orgânica**;

■ **interesse local:** art. 30, I — o interesse local diz respeito às peculiaridades e necessidades ínsitas à localidade. Michel Temer observa que a expressão “interesse local”, doutrinariamente, assume o mesmo significado da expressão “peculiar interesse”, expressa na Constituição de 1967. E completa: “Peculiar interesse significa interesse predominante”; [55](#)

■ **suplementar:** art. 30, II — estabelece competir aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. “No que couber” norteia a atuação municipal, balizando-a dentro do **interesse local**. Observar ainda que tal competência se aplica, também, às matérias do art. 24, suplementando as normas gerais e específicas, juntamente com outras que digam respeito ao peculiar interesse daquela localidade;

■ **plano diretor:** art. 182, § 1.º — o plano diretor deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, sendo obrigatório para cidades com **mais de vinte mil habitantes**. Serve como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana; [56](#)

■ **competência tributária expressa:** art. 156 (estudar especialmente em direito tributário).

■ 7.6.2.3. Competência municipal para legislar sobre meio ambiente (RE 586.224)

Conforme já estudamos, o STF analisou a competência municipal para legislar sobre a **proibição de queimada em canaviais**.

No precedente em análise, de maneira inovadora, a Corte, por unanimidade, “firmou a tese de que **o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da**

7.4.3.4, em que analisamos o tema).

■ 7.7. DISTRITO FEDERAL

■ 7.7.1. Histórico

O **Distrito Federal** surge da transformação do antigo **Município neutro** (sede da Corte e Capital do Império), nos termos do art. 2.º da Constituição de 1891, passando a ser a Capital da União, mantida a sede na cidade do Rio de Janeiro.

Nesse momento de sua instituição não se podia considerá-lo como entidade federada autônoma, mas simples autarquia territorial.

De acordo com o art. 3.º e parágrafo único da Constituição de 1891 (regra essa mantida nos textos seguintes), ficou pertencendo à União, no **Planalto Central** da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que seria oportunamente **demarcada** para nela estabelecer-se a **futura Capital federal**. Efetuada a mudança da Capital, concretizando-se os compromissos de **interiorização do País**, o Distrito Federal, que se localizava na cidade do Rio de Janeiro, passaria a constituir um Estado.

Cumprindo o “Plano de Metas” (“50 anos em 5”), *Juscelino Kubitschek*, além de importantes realizações econômicas, implementou a construção de **Brasília**, inaugurada em **21 de abril de 1960**. Nessa data, conforme mandamento constitucional, o então Distrito Federal foi transformado no **Estado da Guanabara**, com os mesmos limites geográficos da cidade do Rio de Janeiro, a capital e sede do novo Estado (cf. **Lei n. 3.752/60**).

A título de curiosidade, o Estado da Guanabara **não foi dividido em municípios**, decisão essa que encontrou apoio popular no **plebiscito** realizado em 21 de abril de 1963, além de ter **curta duração** (1960-1975). Por força do art. 8.º da **LC n. 20/74**, a partir de 15.03.1975, os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara incorporaram-se entre si (processo de **fusão**), passando a

constituir um único Estado, sob a denominação de **Estado do Rio de Janeiro**, sendo a cidade do Rio de Janeiro a Capital.

Com a Constituição de 1988, de acordo com o art. 18, § 1.º, a Capital Federal passa a ser **Brasília**, situada no território do Distrito Federal, que, no novo modelo, ainda localizado no Planalto Central do Brasil, deixa de ser mera autarquia territorial, tornando-se **ente federativo**, com autonomia parcialmente tutelada pela União, conforme estudaremos.

Brasília, por sua vez, nos termos do art. 6.º da Lei Orgânica do DF, além de ser a Capital da República Federativa do Brasil e sede do governo federal, é, também, **sede do governo do Distrito Federal**.

■ 7.7.2. Distrito Federal como unidade federada

O Distrito Federal é, portanto, uma unidade federada **autônoma**, visto que possui capacidade de **auto-organização**, **autogoverno**, **autoadministração** e **autolegislação**:

■ **auto-organização**: art. 32, *caput* — estabelece que o Distrito Federal se regerá por **lei orgânica**, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal;

■ **autogoverno**: art. 32, §§ 2.º e 3.º — eleição de Governador e Vice-Governador e dos Deputados Distritais;

■ **autoadministração e autolegislação**: regras de competências legislativas e não legislativas, que serão abaixo estudadas.

■ 7.7.3. Outras características importantes

Algumas outras regras devem também ser lembradas:

■ **impossibilidade de divisão do Distrito Federal em Municípios**: o art. 32, *caput*, expressamente, veda a divisão do Distrito Federal em

■ **impossibilidade de divisão do Distrito Federal em Municípios:** o art. 32, *caput*, expressamente, veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, ao contrário do que acontece com os Estados e Territórios;

■ **autonomia parcialmente tutelada pela União:** [57](#) a) o art. 32, § 4.º, declara inexistir polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar, pertencentes ao Distrito Federal. Tais instituições, embora subordinadas ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6.º), são organizadas e mantidas diretamente pela União (art. 21, XIV), sendo que a referida utilização pelo Distrito Federal será regulada por lei federal (cf. [S. 647/STF, 24.09.2003](#) e capítulo sobre *segurança pública*, item 13.7.6); b) também observar que o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios são organizados e mantidos pela União (arts. 21, XIII, e 22, XVII);

EC n. 69/2012: na mesma linha da *Reforma do Poder Judiciário* (EC n. 45/2004), que assegurou às *Defensorias Públicas Estaduais* autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária (dentro dos limites constitucionais), com atraso de 8 anos, a *EC n. 69/2012* **transferiu** da **União** para o **DF** as atribuições de **organizar** e **manter** a **Defensoria Pública do Distrito Federal**, determinando a aplicação dos mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.

A **Lei n. 10.633, de 27.12.2002**, instituiu o **Fundo Constitucional do Distrito Federal — FCDF**, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do DF, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, consoante disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal (cf., ainda, art. 25 da EC n. 19/98).

Entendeu o STF, ainda, que, “ao instituir a chamada ‘gratificação por risco de vida’ dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, o Poder Legislativo distrital usurpou a competência material da União para ‘organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de

Min. Ayres Britto, j. 16.06.2010, Plenário, *DJE* de 27.08.2010).

■ 7.7.4. Competências do Distrito Federal

■ 7.7.4.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)

■ **comum (cumulativa ou paralela):** trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23 da CF/88.

■ 7.7.4.2. Competências legislativas

O art. 32, § 1.º, prescreve que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. Assim, tudo o que foi dito a respeito dos Estados aplica-se ao Distrito Federal, bem como o que foi dito sobre os Municípios no tocante à competência para legislar também a ele se aplica.

■ **expressa:** art. 32, *caput* — elaboração da própria lei orgânica;

■ **residual:** art. 25, § 1.º — toda competência que não for vedada, ao Distrito Federal estará reservada;

■ **delegada:** art. 22, parágrafo único — como vimos, a União poderá autorizar o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência privativa. Tal autorização dar-se-á mediante **lei complementar**;

■ **concorrente:** art. 24 — em que se estabelece concorrência para legislar entre União, Estados e Distrito Federal, cabendo à União legislar sobre normas gerais e ao Distrito Federal, sobre normas específicas;

■ **suplementar:** art. 24, §§ 1.º a 4.º — no âmbito da legislação concorrente, como vimos, a União limita-se a fixar normas gerais e o Distrito Federal, normas específicas. No entanto, em caso de inércia

legislativa da União, o Distrito Federal poderá **suplementá-la** e regulamentar as regras gerais sobre o assunto, sendo que, na superveniência de lei federal sobre norma geral, a aludida norma distrital geral (suplementar) terá a sua eficácia suspensa, no que for contrária à lei federal sobre normas gerais editadas posteriormente; [58](#)

■ **interesse local:** art. 30, I, combinado com o art. 32, § 1.º;

■ **competência tributária expressa:** art. 147, parte final, c/c os arts. 156 e 155 (a estudar especialmente em direito tributário).

■ 7.8. TERRITÓRIOS FEDERAIS

■ 7.8.1. Histórico

Apesar de a primeira Constituição a tratar sobre Territórios ter sido a de **1934**, foi na vigência da de 1891 que se estabeleceu o primeiro Território Federal no Brasil, qual seja, o do **Acre**, [59](#) adquirido pelo Brasil pelo **Tratado de Petrópolis**, assinado em **17.11.1903** com a República da Bolívia e pelo qual se celebrou **permuta de territórios** (destacando que apenas em 08.09.1909 é que se pacificou a controvérsia em relação à fronteira com o Peru — cf. art. VIII do Estatuto).

De acordo com o art. III do referido Tratado, “por não haver equivalência nas áreas dos territórios permutados entre as duas Nações, os Estados Unidos do Brasil **pagarão uma indenização** de 2.000.000 (dois milhões de libras esterlinas), que a República da Bolívia aceita com o propósito de aplicar principalmente na construção de caminhos de ferro ou em outras obras tendentes a melhorar as comunicações e desenvolver o comércio entre os dois países”.

O *Território do Acre* foi organizado pelo **Decreto n. 5.188, de 07.04.1904**, tendo em vista a autorização concedida pelo Decreto Legislativo n. 1.181, de 25 de fevereiro do mesmo ano, e assim permaneceu até a edição da **Lei n. 4.070/62**, sancionada pelo Presidente da República João Goulart, que o **elevou** à

de fevereiro do mesmo ano, e assim permaneceu até a edição da **Lei n. 4.070/62**, sancionada pelo Presidente da República João Goulart, que o **elevou** à categoria de **Estado**.

Posteriormente, sob o fundamento do art. 6.º da Carta de 1937 — “a União poderá criar, no **interesse da defesa nacional**, com partes desmembradas dos Estados, **Territórios Federais**, cuja administração será regulada em lei especial” — e durante a **2.ª Grande Guerra**, Getúlio Vargas, pelos **Decretos-lei ns. 4.102/42** e **5.812/43**, criou, com partes **desmembradas** dos Estados do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina, os seguintes Territórios Federais:

■ **Fernando de Noronha**: extinto nos termos do art. 15, ADCT, CF/88, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco. Atualmente, conforme estudaremos a seguir, o arquipélago é um distrito estadual;

■ **Amapá**: transformado no **Estado do Amapá** pelo art. 14, ADCT, CF/88, mantidos seus limites geográficos;

■ **Rio Branco**: a Lei n. 4.182/62 passou a denominá-lo *Território Federal de Roraima*. Foi transformado no **Estado de Roraima** pelo art. 14, ADCT, CF/88, mantidos seus limites geográficos;

■ **Guaporé**: a Lei n. 2.731/56, em homenagem ao sertanista *Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon*, mudou a denominação do *Território Federal do Guaporé* para **Território Federal de Rondônia**. A **LC n. 41/81**, por sua vez, criou o **Estado de Rondônia**, mediante a elevação do então Território Federal, mantidos os seus limites e confrontações;

■ **Ponta Porã**: o art. 8.º, ADCT, da Constituição de 1946 determinou a sua reincorporação ao então Estado de Mato Grosso. Atualmente, a área encontra-se no *Estado de Mato Grosso do Sul* (criado por desmembramento de Mato Grosso pela LC n. 31/1977);

■ **Iguaçu**: o art. 8.º, ADCT, da Constituição de 1946 determinou a sua reincorporação aos Estados do Paraná e de Santa Catarina.

■ 7.8.2. Natureza jurídica

política. Trata-se de mera **descentralização administrativo-territorial da União**, qual seja, uma **autarquia** que, consoante expressamente previsto no art. 18, § 2.º, **integra a União**.

■ 7.8.3. Ainda existem territórios no Brasil?

NÃO.

Conforme estudamos, até o advento da Constituição de 1988 havia três territórios: **Roraima, Amapá e Fernando de Noronha**:

■ **Roraima:** foi transformado em Estado, de acordo com o art. 14, *caput*, do ADCT;

■ **Amapá:** também foi transformado em Estado, de acordo com o art. 14, *caput*, do ADCT;

■ **Fernando de Noronha:** foi extinto, sendo a sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco (art. 15, ADCT, CF/88).

■ 7.8.4. Mas, afinal de contas, o que é Fernando de Noronha?

Dizer, nos termos do art. 15 do ADCT, que sua área foi reincorporada ao Estado de Pernambuco não é suficiente. Então, expliquemos melhor a matéria.

De acordo com o art. 96 da CE/PE, o Arquipélago de Fernando de Noronha constitui *região geoeconômica, social e cultural do Estado de Pernambuco*, sob a forma de *Distrito Estadual, dotado de estatuto próprio, com autonomia administrativa e financeira*.

Já o parágrafo único do art. 1.º da Lei estadual n. 11.304, de 28.12.1995 (do Estado de Pernambuco), caracteriza o **Distrito Estadual de Fernando de Noronha** como uma *entidade autárquica integrante do Poder Executivo Estadual, exercendo, sobre toda a extensão da área territorial do Arquipélago de Fernando de Noronha, jurisdição plena atribuída às competências estadual e municipal, bem como os poderes administrativos e de polícia próprios de*

ente público.

O Distrito Estadual tem por **sede** o Palácio São Miguel, situado na Vila dos Remédios, na Ilha de Fernando de Noronha, e por **foro** a Comarca do Recife, tendo por competência prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar da população insular.

O § 1.º do art. 96 da CE/PE determina que o **Distrito Estadual de Fernando de Noronha** será dirigido por um **Administrador-Geral, nomeado** pelo Governador do Estado, com **prévia aprovação da Assembleia Legislativa**, e o § 2.º estabelece a **eleição direta**, pelo voto secreto, concomitantemente com a eleição de Governador de Estado, pelos **cidadãos residentes no Arquipélago**, de **7 Conselheiros**, com mandato de **4 anos**, para formação do **Conselho Distrital**, órgão que terá funções consultivas e de fiscalização, na forma da lei.

Muito embora Fernando de Noronha atualmente seja um **Distrito Estadual**, o § 3.º do art. 96 da CE/PE prevê a sua transformação em Município quando alcançar os requisitos e as exigências mínimas, previstos em lei complementar estadual.

■ 7.8.5. Apesar de não existirem, podem vir a ser criados novos territórios?

SIM.

Como vimos, o Poder Constituinte de 1988 transformou dois territórios em Estados e extinguiu o terceiro, ainda existentes em 1988.

Apesar disso, é **perfeitamente possível a criação de novos territórios federais**, que, com certeza, continuarão a ser mera autarquia, sem qualquer autonomia capaz de lhes atribuir a característica de entes federados. O processo de criação dar-se-á da seguinte forma:

- **lei complementar:** a criação de novos territórios dar-se-á mediante **lei complementar**, conforme o art. 18, § 2.º;
- **plebiscito:** deve haver plebiscito aprovando a criação do território;

■ **modo de criação:** o art. 18, § 3.º, dispõe que os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros, ou formar **Territórios Federais**, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do Congresso Nacional, por **lei complementar**.

■ 7.8.6. Outras características importantes

Algumas outras regras devem também ser lembradas:

■ **lei federal:** de acordo com o art. 33, *caput*, lei federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios;

■ **divisão em municípios:** ao contrário do que ocorre com o Distrito Federal, o art. 33, § 1.º, prevê a possibilidade de os Territórios, quando criados, serem divididos em Municípios, aos quais serão aplicadas as regras dos arts. 29 a 31 da CF/88;

■ **Executivo:** a direção dos Territórios, se criados, dar-se-á por Governador, nomeado pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal (art. 84, XIV);

■ **Legislativo (CN):** nos termos do art. 45, § 2.º, cada Território elegerá o número fixo de **4 deputados federais**, caracterizando-se, assim, exceção ao princípio proporcional para a eleição de deputados federais, ou seja, não existirá variação do número de representantes da população local dos Territórios;

■ **controle das contas:** a fiscalização das contas do governo do Território caberá ao Congresso Nacional, após o parecer prévio do Tribunal de Contas da União (art. 33, § 2.º);

■ **Judiciário, Ministério Público e defensores públicos federais:** nos Territórios Federais com mais de 100 mil habitantes, além do Governador nomeado na forma da Constituição (art. 84, XIV), haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, organizados e mantidos pela União (art. 33, § 3.º, c/c o art. 21, XIII). Ainda, nos termos do parágrafo único do art.

110, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais (Justiça Federal Comum) caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei;

■ **Polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar dos Territórios federais:** muito embora os Territórios sejam uma descentralização administrativa da União, integrando-a, a EC n. 19/98, alterando a redação do art. 21, XIV, da CF/88, não mais atribuiu à União a organização e manutenção da polícia civil, militar e do corpo de bombeiros dos Territórios, endereçando referida regra **exclusivamente** ao Distrito Federal;

■ **Legislativo:** a lei disporá sobre as eleições para a **Câmara Territorial** e sua competência deliberativa (art. 33, § 3.º);

■ **Sistema de ensino:** organizado pela União, nos termos do art. 211, § 1.º.

■ 7.9. MODELOS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A Constituição fixa, de maneira clara, a **repartição de competências** entre os entes federativos, que, conforme visto, são autônomos cada qual dentro de sua parcela de atribuições e capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação (com as especificidades já apontadas, sobretudo em relação ao DF, cuja autonomia é parcialmente tutelada pela União).

As **atribuições** estão estabelecidas pelo constituinte originário e, em tese, poderiam ser objeto de modificação (por emenda), desde que a novidade, a ser introduzida, não violasse a forma federativa de Estado, bem como as demais cláusulas pétreas.

Portanto, teoricamente, para se ter um exemplo, seria possível que determinada emenda transferisse a competência para legislar sobre direito penal, que hoje é reservada à União (art. 22, I), para os Estados, apesar de críticas que possam surgir nesse sentido. Parece-nos que, no exemplo citado, haveria, inclusive, fortalecimento da autonomia federativa estadual. A questão fica, então, dentro de um campo de conveniência política.

Pois bem, essa repartição de competências dá-se de acordo com alguns **modelos**, segundo a doutrina.

■ 7.9.1. Modelo clássico e modelo moderno

No **direito comparado** houve a formulação tanto de um modelo **clássico** como de um modelo **moderno**, tendo como parâmetro a enumeração ou não das atribuições. Vamos a eles.

■ 7.9.1.1. Modelo clássico

O **modelo clássico** busca a sua fonte na *Constituição norte-americana de 1787*, refletindo aspirações do final do século XVIII.

Conforme esse modelo, compete à **União** exercer os poderes **enumerados** e aos **Estados**, os poderes não especificados, em um campo **residual**.

Como bem anota Paulo Branco,⁶⁰ o rigorismo da enunciação taxativa é flexibilizado pela **doutrina dos poderes implícitos**.

Isso porque, nas palavras de Raul Machado Horta, “o sentido premonitório do Constituinte de Filadélfia resguardou o desenvolvimento dos poderes enumerados quando reconheceu expressamente ao Congresso a competência ‘para elaborar todas as leis necessárias e adequadas ao exercício dos poderes especificados e dos demais poderes conferidos por esta Constituição ao governo dos Estados Unidos ou aos seus departamentos ou funcionários’ (...) a famosa cláusula dos **poderes implícitos**, que na Corte Suprema Norte-Americana converteu no fundamento de dilatadora construção constitucional na via judicial”.⁶¹

■ 7.9.1.2. Modelo moderno

O **modelo moderno**, por sua vez, passou a ser verificado após a Primeira Guerra Mundial, estando descritas nas Constituições não somente as atribuições

exclusivas da União, como, também, as hipóteses de competência comum ou concorrente entre a União e os Estados.

Para Paulo Branco, “o chamado *modelo moderno* responde às contingências da crescente complexidade da vida social, exigindo ação **dirigente** e **unificada** do Estado, em especial para enfrentar as crises sociais e guerras”.[62](#)

■ 7.9.2. Modelo horizontal e modelo vertical

Outra classificação, segundo a doutrina, leva em conta não a enumeração das atribuições, mas, partindo delas, se haverá ou não condomínio entre os entes federativos para a sua realização e, assim, vislumbrando tanto um modelo *horizontal* como um modelo *vertical*.

■ 7.9.2.1. Modelo horizontal

No **modelo horizontal** não se verifica concorrência entre os entes federativos. Cada qual exerce a sua atribuição nos limites fixados pela Constituição e **sem relação de subordinação**, nem mesmo hierárquica.

Ensina Paulo Branco que “esse modelo apresenta três soluções possíveis para o desafio da distribuição de poderes entre órbitas do Estado Federal. **Uma delas** efetua a enumeração exaustiva da competência de cada esfera da Federação; **outra**, discrimina a competência da União deixando aos Estados-membros os poderes reservados (ou não enumerados); a **última** discrimina os poderes dos Estados-membros, deixando o que restar para a União”.[63](#)

No **Brasil** predomina o **modelo horizontal**, nos termos dos arts. 21, 22, 23, 25 e 30.

■ 7.9.2.2. Modelo vertical

No **modelo vertical**, por sua vez, a mesma matéria é **partilhada** entre os diferentes entes federativos, havendo, contudo, certa relação de subordinação no

que tange à atuação deles.

Em se tratando de competência legislativa, geralmente a **União** fica com **normas gerais** e **princípios**, enquanto os **Estados**, completando-as, legislam para atender às suas **peculiaridades** locais.

O modelo vertical pode ser caracterizado, na lição de Paulo Branco, como uma técnica que estabelece “um verdadeiro **condomínio legislativo** entre a União e os Estados-membros”.⁶⁴

Como exemplo de modelo vertical, no Brasil, podemos citar as matérias de **competência concorrente** entre a União, os Estados e o Distrito Federal, estabelecidas no art. 24 da CF/88.

Vimos que, no âmbito da **competência legislativa concorrente**, a União limita-se a estabelecer normas gerais e os Estados, normas específicas. No entanto, em caso de inércia legislativa da União, os Estados poderão suplementá-la, regulamentando as regras gerais sobre o assunto. Esse modelo, contudo, parece ter sofrido certa alteração, em uma verdadeira ponderação de valores, conforme propomos no *item 7.11* a seguir, remetendo o nosso ilustre leitor para a importante discussão sobre o **amianto** e o **tabaco**.

Finalmente, constata-se que no **modelo vertical** há uma maior **aproximação** entre os entes federativos, que deverão atuar em complemento, em “**condomínio legislativo**”. Já no **modelo horizontal**, parece haver um maior afastamento, na medida em que a distribuição de competência se mostra bastante **rígida** e sem interferência de um sobre outro.

■ 7.10. QUADRO ILUSTRATIVO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL — ALGUNS PRECEDENTES DO STF

O objetivo desta parte do estudo é indicar algumas interpretações fixadas pelo STF em relação ao modelo constitucional de repartição de competências.

Sem dúvida, na prática vêm sendo observados conflitos na atuação governamental e legislativa e, então, o STF surge para afirmar a verdadeira força normativa da Constituição definindo, com precisão, a atribuição de cada ente

federativo.

Não se pode falar em hierarquia de atos normativos. Existem **campos de atribuição**, definidos pelo constituinte originário. Não se pode afirmar, por exemplo, que a lei municipal é hierarquicamente inferior a certa lei federal. No fundo, o que se tem são campos de atuação e, portanto, se, eventualmente, determinado Município legisla sobre assunto de competência da União, o vício não é legislativo (entre as leis), mas, em essência, **constitucional**, ou seja, em relação à competência federativa para legislar sobre aquele assunto.

Por esse motivo é que, de maneira coerente, a EC n. 45/2004 estabeleceu que cabe **recurso extraordinário** para o **STF** quando, nos termos do art. 102, III, “d”, se julgar válida lei local contestada em face de lei federal. O vício que eventualmente a lei conterà será um **vício formal orgânico**, ou seja, em relação ao ente federativo que deveria legislar sobre aquele assunto (cf. *item 6.3.2.1*).

MATÉRIA	JULGADO/PRECEDENTE	COMPETÊNCIA PARALEGISLAR
■ Loterias e jogos de bingo. Regras de exploração. Sistemas de consórcios e sorteios. Direito penal	■ ADI 2.847/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, <i>DJ</i> de 26.11.2004; ADI 2.948/MT, Rel. Min. Eros Grau, <i>DJ</i> de 13.05.2005; ADI 2.690, Rel. Min. Gilmar Mendes, <i>DJ</i> de 16.06.2006; ADI 3.259, Rel. Min. Eros Grau, <i>DJ</i> de 24.02.2006; ADI 2.995, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, <i>DJ</i> de 21.08.2006; ADI 3.148, Rel. Min. Celso de Mello, <i>DJ</i> de 28.09.2007 ■ SV 2/2007-STF : “É	■ União — art. 22, I (direito penal) e art. 22, XX (sistema de consórcios e sorteios)

	inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”	
■ Gratuidade de estacionamento em estabelecimento privado (<i>shopping centers</i>, hipermercados, instituições de ensino, rodoviárias e aeroportos)	■ ADI 3.710/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 09.02.2007 (reconhecimento de vício formal em relação à Lei n. 15.223/2005, do Estado de Goiás). Nesse sentido, cf. ADI 1.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.03.2011	■ União — art. 22, I (direito civil — limitação genérica ao exercício do direito de propriedade)
■ Aquisição de propriedade	■ ADI 3.438/PA, Rel. Min. Carlos Velloso, 19.12.2005 (<i>Inf. 413/STF</i>)	■ União — art. 22, I (direito civil)
■ Lei n. 2.089/93, do Estado do Rio de Janeiro, que estabelecia a obrigatoriedade da numeração dos rótulos ou tampinhas das bebidas comercializadas no mencionado Estado, independentemente de sua procedência, para efeito de arrecadação de impostos	■ Precedente citado: ADI 750-MC/RJ (<i>DJU</i> de 11.09.1992), ADI 910-RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, 20.08.2003 (<i>Inf. 317/STF</i>)	■ União — art. 22, VIII (comércio exterior e interestadual)

estaduais — inconstitucional		
■ Lei n. 10.553/2000, do Estado de São Paulo, que impunha condições para a cobrança pelo Poder Público de multas provenientes de aparelhos eletrônicos sobre infrações cometidas por motoristas condutores de veículos automotores — inconstitucional	■ Precedentes citados: ADI 1.991-MC/DF (<i>DJU</i> de 25.06.1999), ADI 2.064-MC/MS (<i>RTJ</i> 171/138) e ADI 2.101-MC/MS (<i>DJU</i> de 28.04.2000). ADI 2.328/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 17.03.2004 (<i>Inf.</i> 340/<i>STF</i>)	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Lei n. 8.027/2003, do Estado de Mato Grosso, que autorizou o parcelamento de multa vencida, resultante de infração de trânsito, e sua norma regulamentadora, Decreto n. 3.404/2004 — inconstitucional (nulificação do decreto por arrastamento)	■ ADI 3.708, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.04.2013, Plenário. No mesmo sentido, cf. ADI 4.734/AL, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.05.2013	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte) ■ Voto vencido: esforço do Poder Público em arrecadar o valor das multas. Não se trata de trânsito, mas de receita
■ Lei n. 3.279/99, do Estado do Rio de Janeiro, que cancelou (em ato de inegável anistia) multas de trânsito aplicadas em rodovias do referido	■ ADI 2.137, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.04.2013,	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)

Estado, em certo período, relativas a uma classe específica de veículos — inconstitucional		
■ Lei n. 11.604/2001, do Estado do Rio Grande do Sul, de iniciativa parlamentar, que dispunha sobre a sinalização de rodovias estaduais, estabelecendo o controle eletrônico de velocidade, a forma de sua sinalização e divulgação nos meios de comunicação, a estipulação de velocidade mínima nas rodovias, a obrigatoriedade da construção de vias laterais de circulação e as formas de notificação das multas lavradas — inconstitucional	■ Precedentes citados: ADI 2.064-MS (<i>DJU</i> de 17.08.2001), ADI 2.137-MC/RJ (<i>DJU</i> de 12.05.2000) e ADI 2.328-MC/SP (<i>DJU</i> de 15.12.2000). ADI 2.802-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 09.10.2003 (<i>Inf. 324/STF</i>)	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Lei n. 13.279/2001, do Estado do Paraná, que fixava em no máximo 20% do valor do automóvel as multas impostas pelo DETRAN/PR, autuadas a partir de janeiro de 2000 — inconstitucional	■ Precedentes citados: ADI 2.328-MC/SP (<i>DJU</i> de 15.12.2000), ADI 2.137-MC/RJ (<i>DJU</i> de 12.05.2000) e ADI 2.432-MC/RN (<i>DJU</i> de 21.09.2001). ADI 2.644-PR, Rel. Min. Ellen Gracie, 07.08.2003 (<i>Inf. 315/STF</i>)	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)

	07.08.2003 (<i>Inf. 315/STF</i>)	
■ Película de filme solar nos vidros dos veículos automotores	■ ADI 1.704-MT, Rel. Min. Carlos Velloso, 1.º.08.2002 (<i>Inf. 275/STF</i>)	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Lei n. 6.457/93, do Estado da Bahia, que obrigou, dentro do prazo de 120 dias a contar de sua publicação, as empresas de transporte coletivo de passageiros, que operam no território do referido Estado, a instalarem cinto de segurança na totalidade dos veículos que compõem as respectivas frotas — inconstitucional	■ ADI 874, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2011, Plenário, <i>DJE</i> de 28.02.2011. No mesmo sentido: RE 215.325-RS; RE 227.384-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 17.06.2002 (<i>Inf. 273/STF</i>)	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte) ■ Inexistência de LC autorizando os Estados a legislar sobre questão específica, nos termos do art. 22, parágrafo único, da CF/88
■ Lei n. 10.521/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que dispôs sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e proibiu os menores de 10 anos de viajar nos bancos dianteiros dos veículos que menciona — inconstitucional	■ ADI 2.960, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.04.2013, Plenário, <i>DJE</i> de 09.05.2013	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Lei n. 8.493/2004, do Rio Grande do Norte, que		

particulares apreendidos que se encontrem nos pátios das Delegacias e no Detran, e que foram modificados há mais de 90 dias, em serviços de Inteligência e Operações Especiais relacionadas à Secretaria de Defesa Social, sendo a sua utilização subordinada à autorização exclusiva do Secretário de Defesa Social — inconstitucional	■ ADI 3.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23.05.2013, Plenário, <i>DJE</i> de 07.10.2013	■ União — arts. 5.º, <i>caput</i> , XXV e XLV, e 22, I, III e XI (direito penal, requisição administrativa, trânsito e perdimento de bens)
■ Lei Distrital n. 1.925/98 que torna obrigatória, sob pena pecuniária a ser definida pelo Poder Executivo, a iluminação interna dos veículos fechados, no período das dezoito às seis horas, quando se aproximem de blitz ou barreira policial — inconstitucional	■ ADI 3.625, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04.03.2009, Plenário, <i>DJE</i> de 15.05.2009	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Lei distrital ou estadual que comine penalidades a quem seja flagrado em estado de embriaguez na condução de veículo automotor —	■ ADI 3.269, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 1.º.08.2011, Plenário, <i>DJE</i> de 22.09.2011	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)

automotor — inconstitucional		
■ Lei n. 11.766/97, do Estado do Paraná, que torna obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos nas rodovias do Estado do Paraná, impondo a pena de multa aos que descumprirem o preceito legal — inconstitucional	■ ADI 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 24.11.2005, Plenário, <i>DJ</i> de 03.02.2006	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Lei n. 10.884/2001, do Estado de São Paulo, que estabelece a obrigatoriedade de reserva de espaço para o tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação da Região Metropolitana de São Paulo, assim consideradas pela autoridade de trânsito, sob pena das penalidades do <i>Código de Trânsito Brasileiro</i> — inconstitucional	■ ADI 3.121, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.03.2011, Plenário, <i>DJ</i> de 14.04.2011	■ União — art. 22, XI (trânsito e transporte)
■ Legislação sobre mototáxi. Serviço de trans-		

passageiros prestado por meio de ciclomotores, motonetas e motocicletas (sistema de <i>moto-service</i> — transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas)	Sepúlveda Pertence, j. 18.06.2007, Plenário, <i>DJ</i> de 03.08.2007. Precedentes citados: ADI 2.606; ADI 3.135; ADI 3.136	(trânsito e transporte) ■ A matéria foi regulamentada pela Lei Federal n. 12.009/2009
■ Lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga respeito à segurança de trânsito, como, no caso, à profissão de <i>motoboy</i> — inconstitucional	■ ADI 3.610, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 1.º.08.2011, Plenário, <i>DJE</i> de 22.09.2011	■ União — art. 22, I, XI e XVI (direito do trabalho, trânsito e transporte e condições para o exercício de profissões)
■ Art. 185 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que estabelecia que a implantação de instalações industriais para produção de energia nuclear no mencionado Estado dependeria de autorização prévia da Assembleia Legislativa local, ratificada por plebiscito — inconstitucional	■ Precedentes citados: Rp 1.130/RS (<i>DJU</i> de 30.11.1984) e Rp 1.233/RJ (<i>DJU</i> de 06.09.1985). ADI 329/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, 1.º.04.2004 (<i>Inf. 342/STF</i>) No mesmo sentido: ADI 1.575, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07.04.2010, Plenário, <i>DJE</i> de 11.06.2010	■ União — art. 22, XXVI (atividades nucleares de qualquer natureza)
■ Lei n. 11.908/2001, do		

■ Lei n. 11.908/2001, do Estado de Santa Catarina, que fixa condições de cobrança da assinatura básica residencial ou equivalente de telefonia — inconstitucional	■ ADI 2.615, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 11.03.2015, Plenário, <i>DJE</i> de 18.05.2015	■ União — arts. 21, XI, e 22, IV (telecomunicações)
■ Lei n. 12.427/2006, do Estado do Rio Grande do Sul, que proíbe a comercialização, a estocagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, cevada e aveia e seus derivados importados de outros países, para consumo e comercialização no referido Estado, que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos ou de princípios ativos usados, também, na industrialização dos referidos produtos — inconstitucional	■ ADI 3.813, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.02.2015, Plenário	■ União — art. 22, VIII (comércio exterior)
■ Lei n. 12.635/2005, do Estado de São Paulo, que assegura a remoção, sem qualquer ônus para os interessados, desde que		■ União — arts. 21, XII,

remoção anterior, dos postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos comissários compradores de terrenos — inconstitucional	■ ADI 4.925, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015, Plenário	elétrica e termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão)
■ Contratação de controladores de velocidade para fins de fiscalização nas rodovias estaduais	■ ADI 2.665/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, 27.10.2004 — a norma impugnada não invade a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e sobre normas gerais de licitação e contratação (CF, art. 22, XI e XXVII) (<i>Inf. 367/STF</i>)	■ Estados — art. 25, § 1.º
■ Limite de tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios localizados no seu respectivo território	■ RE 240.406/RS (<i>DJU</i> de 30.04.2004); AI 506.487 AgR/PR (<i>DJU</i> de 17.12.2004); RE 432.789/SC (<i>DJU</i> de 05.05.2006); RE 418.492 AgR/SP (<i>DJU</i> de 03.03.2006); RE 397.094/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 29.08.2006	■ Municípios — interesse local — art. 30, I ■ DF — lei distrital de natureza municipal (art. 32, § 1.º, c/c o art. 30, I) — cf. RE 397.094/DF

■ Lei estadual n. 12.775/2003, de Santa Catarina, que determinou às agências bancárias estabelecidas no território catarinense a obrigatoriedade do uso de equipamento para atestar a autenticidade de cédulas de dinheiro nas transações bancárias, devendo tal equipamento ser aquele indicado pelo Banco Central do Brasil — inconstitucional	■ ADI 3.515, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 1.º.08.2011, Plenário, <i>DJE</i> de 29.09.2011	■ União — arts. 21, VIII, 22, VII, e 192
■ Bancos — Lei Municipal que determina medidas de conforto aos usuários (clientes ou não), como instalações sanitárias, fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros, bem como equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança, tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras — constitucional	■ AI 347.717-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello (cf. <i>Inf.</i> 394/STF)	■ Municípios — interesse local — art. 30, I
		■ União, Estados e DF — competência concorrente

■ Meia-entrada para estudantes do valor cobrado para o ingresso em eventos esportivos, culturais e de lazer — constitucional	■ ADI 1.950/SP, Rel. Min. Eros Grau, 03.11.2005 (<i>Inf. 407/STF</i>)	— art. 24, I (direito econômico) ■ Em momento posterior ao julgamento, destacamos o advento da Lei (federal) n. 12.933/2013, que dispôs sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos (cf. art. 24, §§ 1.º a 4.º, CF/88)
■ Lei n. 7.737/2004, do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia-entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal	■ ADI 3.512, Rel. Min. Eros Grau, j. 15.02.2006, <i>DJ</i> de 23.06.2006	■ União, Estados e DF — competência concorrente — art. 24, I (direito econômico) ■ Em momento posterior ao julgamento, destacamos o advento da Lei (federal) n. 12.933/2013, que dispôs sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com

Estados e o Distrito Federal — constitucional		deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos (cf. art. 24, §§ 1.º a 4.º, CF/88)
■ Lei Estadual reservando assentos para as pessoas obesas em salas de projeções, teatros e espaços culturais no Estado do Paraná	■ ADI 2.477-MC/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão (<i>Inf. 265/STF</i> — matéria pendente de julgamento do mérito pelo STF)	■ União, Estados e DF — competência concorrente — proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência física (obesidade mórbida — art. 24, XIV)
■ Lei n. 5.652/98, do Estado do Espírito Santo, que disciplina a comercialização de produtos por meio de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis. Gás liquefeito de petróleo engarrafado (GLP). Diretrizes relativas à requalificação dos botijões. (...) — constitucional	■ ADI 2.359, Rel. Min. Eros Grau, j. 27.09.2006, Plenário, <i>DJ</i> de 07.12.2006. No mesmo sentido: ADI 2.818, rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.05.2013	■ União, Estados e DF — competência concorrente — art. 24, V e VIII (proteção do consumidor)
■ Lei n. 10.820/92, do Estado de Minas Gerais, que obriga as empresas		■ União, Estados e DF — competência concorrente — art. 24, XIV (proteção e integração social das

transporte coletivo intermunicipal “a promoverem adaptações em seus veículos, a fim de se facilitar o acesso e a permanência de portadores de deficiência física e de pessoas com dificuldades de locomoção” — constitucional	■ ADI 903, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2013, Plenário	pessoas portadoras de deficiência). Cf.: arts. 227, § 2.º, e 244. O Estado exerceu a competência legislativa plena porque, à época, não existia a lei federal (nacional) geral n. 10.098/2000 — art. 24, § 3.º
■ Lei n. 1.504/89, do Estado do Rio de Janeiro, que regula a homologação judicial de acordo sobre a prestação de alimentos firmada com a intervenção da Defensoria Pública. De acordo com a regra estadual, o Defensor Público terá a iniciativa de promover, junto ao Juízo competente, a designação de dia e hora para a audiência dos interessados e eventual homologação do acordo que terá força executória — constitucional	■ ADI 2.922, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.04.2014, Plenário, <i>DJE</i> de 30.10.2014	■ União, Estados e DF — competência concorrente — art. 24, XI e XII (procedimento em matéria processual e assistência jurídica e defensoria pública)
		■ União — art. 22, I (direito processual) ■ Destacamos o voto

■ Lei Estadual disciplinando sobre o interrogatório por videoconferência — inconstitucional	■ HC 90.900 — Rel. p/ o acórdão Min. Menezes Direito, j. 30.10.2008, Plenário, <i>DJE</i> de 23.10.2009 (<i>Inf. 526/STF</i>)	vencido da Min. Ellen Gracie, que entendia constitucional a lei paulista por se tratar, em sua argumentação, não de direito processual, mas de procedimento em matéria processual (art. 24, XI) ■ Atualmente, o tema é disciplinado na Lei Federal n. 11.900/2009 (cf. <i>item 14.10.29.2</i>)
■ Lei n. 7.716/2001, do Estado do Maranhão, que estabelece prioridade na tramitação processual, em qualquer instância, para as causas que tenham, como parte, mulher vítima de violência doméstica — inconstitucional	■ ADI 3.483, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.04.2014, Plenário, <i>DJE</i> de 14.05.2014	■ União — art. 22, I (direito processual)
■ Lei municipal legislando sobre horário de funcionamento de comércio local, como o das farmácias — constitucional (OBS.: de acordo com o STF, lei municipal não está autorizada — já que extrapolaria e transcenderia	■ SV. 38/STF: “é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial” (esta súmula vinculante, aprovada em 11.03.2015, é fruto de conversão do	■ Municípios — interesse local — art. 30, I

horário de funcionamento de instituição financeira)	645/STF)	
■ Lei municipal legislando sobre a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo — inconstitucional	■ SV 49/STF: “ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área” (j. 17.06.2015 — conversão da S. 646/STF)	■ Cf. art. 170, IV, da CF
■ Lei n. 1.317/2004, do Estado de Rondônia, que autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas — inconstitucional	■ ADI 3.258, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2005, Plenário, <i>DJ</i> de 09.09.2005. No mesmo sentido: ADI 3.193, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2013, Plenário, <i>DJE</i> de 06.08.2013	■ União — arts. 21, VI, e 22, I e XXI ■ A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular ■ “A técnica da remissão a lei federal, tomando-se de empréstimo preceitos nela contidos, pressupõe a possibilidade de o Estado legislar, de modo

		possibilidade de o Estado legislar, de modo originário, sobre a matéria” (ADI 3.193)
■ LC n. 240/2002, do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre garantias e prerrogativas dos Procuradores de Estado, prescrevendo o fornecimento de carteira de identidade com porte de arma, independentemente de qualquer ato formal de licença ou autorização, para fins de uso em suas atribuições — inconstitucional	■ ADI 2.079, Rel. orig. Min. Luiz Fux, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 19.06.2013	■ União — arts. 21, VI, e 22, I. Para o Min. Gilmar Mendes, “a posse, comercialização e uso de armas de fogo estão regulados pela Lei federal 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), cuja constitucionalidade já foi reconhecida pela Suprema Corte no julgamento da ADI 3.112, ante o entendimento de que cabe à União a competência para legislar em matérias de predominante interesse geral, como é o porte de armas” (<i>Notícias STF</i> de 19.06.2013)
■ Legislar sobre serviço postal	■ ADI 3.080, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02.08.2004, Plenário, <i>DJ</i> de 27.08.2004	■ União — arts. 21, X, e 22, V ■ IMPORTANTE: Em relação à manutenção do monopólio dos Correios (art. 21, X), cf. <i>capítulo 20</i>, ADPF 46, j. 05.08.2009

■ Lei n. 1.314, de 1.º.04.2004, do Estado de Rondônia, que impõe às empresas de construção civil, com obras no Estado, a obrigação de fornecer leite, café e pão com manteiga aos trabalhadores que comparecerem com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos ao seu primeiro turno de labor — inconstitucional	■ ADI 3.251, Rel. Min. Carlos Britto, j. 18.06.2007, <i>DJ</i> de 19.10.2007	■ União — art. 22, I (direito do trabalho)
■ Lei Distrital. Notificação mensal à secretaria de saúde. Casos de câncer de pele. Obrigação imposta a médicos públicos e particulares. Admissibilidade. Saúde pública. Matéria inserida no âmbito de competência comum e concorrente do Distrito Federal ■ Agora, cuidado: a imputação de responsabilidade civil ao médico por falta de notificação caracteriza ofensa ao art. 22, I (direito civil)	■ ADI 2.875, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2008, <i>DJE</i> de 20.06.2008	■ União, Estados e DF — competência concorrente — arts. 23, II, e 24, XII, da CF (proteção e defesa da saúde — notificação compulsória) ■ União — art. 22, I, a imputação de responsabilidade civil (havendo, nesse ponto, portanto, vício formal)

■ LC n. 170/98, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o número máximo de alunos em sala de aula na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio — constitucional	■ ADI 4.060, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.02.2015, Plenário	■ União, Estados e DF — competência concorrente — art. 24, IX, da CF (educação)
■ Matéria concernente a relações de trabalho. Lei estadual ou distrital que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no respectivo território — inconstitucional	■ ADI 2.947, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.05.2010, Plenário, <i>DJE</i> de 10.09.2010	■ União — art. 22, I (direito do trabalho). Cf., também, art. 21, XXIV (inspeção do trabalho)
■ Lei Distrital n. 3.449/2004 e Lei Amapaense n. 1.336/2009 que vedam a cobrança de tarifas e taxas de consumo mínimas ou de assinatura básica, impostas por concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, tv a cabo e telefonia — no caso da lei distrital — e por prestadoras de serviço de	■ ADI 3.343 e ADI 4.478, Rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. 1.º.09.2011, Plenário (<i>Inf. 638/STF</i>). No mesmo sentido: ADI 3.847, ADI 4.369, ADI 4.401	■ União — arts. 21, XI; 22, IV; e 175, parágrafo único, III ■ O STF entendeu que, embora se tratasse de relação de consumo, as regras deveriam ser ditadas pelo poder concedente, ou seja, incumbiria à União estabelecer quais seriam os preços compatíveis com a manutenção de serviços e

telefonia fixa e móvel — no caso da lei estadual — inconstitucionais		com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato previamente firmado
■ Leis fluminenses ns. 3.915/2002 e 4.561/2005 que obrigam as concessionárias dos serviços de telefonia fixa, energia elétrica, água e gás a instalar medidores de consumo — inconstitucionais	■ ADI 3.558, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.03.2011, Plenário, <i>DJE</i> de 06.05.2011	■ União — arts. 21, XI e XII, “b”; e 22, IV (deve ser respeitada a relação firmada entre a União e suas concessionárias)
■ Lei distrital n. 3.426/2004 que obriga as empresas concessionárias, prestadoras de serviços de telefonia fixa, a individualizar determinadas	■ ADI 3.322, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.	■ União — art. 22, I (ônus da prova — direito processual) ■ União — arts. 21, XI, 22, IV (telecomunicações), e 175 ■ Necessidade de obediência aos contratos firmados entre o Poder Público federal concedente e as concessionárias de serviços públicos ■ “A lei a que se refere o parágrafo único do art. 175 deve ser editada,

telefonia fixa, a individualizar determinadas informações nas faturas, bem como fixa ônus da prova para referidas empresas em caso de contestação das cobranças pelos consumidores — inconstitucional	■ ADI 3.322, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.12.2010, Plenário, <i>DJE</i> de 29.03.2011. No mesmo sentido, cf. ADI 4.083	parágrafo único do art. 175 deve ser editada, necessariamente, pelo ente político responsável pela prestação do serviço. Nesse sentido, cabendo à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações (art. 21, XI, acrescente-se), compete-lhe privativamente legislar sobre o regime das concessionárias, questões relativas a contrato, direitos dos usuários, política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado” (voto do Min. Gilmar Mendes)
■ A Constituição do Amapá garantiu o direito à “meia-passagem” aos estudantes, nos transportes coletivos municipais — inconstitucional por invadir		■ Município — art. 30, V (serviço público de interesse local, incluído o transporte coletivo) ■ Estadual — art. 25, § 1.º (competência residual estadual para legislar sobre transporte intermunicipal)

competência para legislar sobre a prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-Membros. “Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido pela Constituição estadual, de ‘meia passagem’ aos estudantes nos transportes coletivos intermunicipais”	■ ADI 845, Rel. Min. Eros Grau, j. 22.11.2007, Plenário, <i>DJE</i> de 07.03.2008	da União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. CUIDADO: a) <i>transporte dentro do Município</i> — competência municipal; b) <i>transporte intermunicipal</i> — competência estadual; c) <i>transporte interestadual ou internacional</i> — competência da União
■ Lei distrital n. 3.426/2004, que dispunha sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias, prestadoras de serviços de telefonia fixa, individualizarem, nas faturas, as informações que especificam, sob pena de multa — inconstitucional	■ ADI 3.322/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.12.2010 (cf. <i>Inf. 611/STF</i>)	■ União — arts. 21, XI; 22, IV; e 175 (telecomunicações)
■ “Mensalidades escolares. Fixação da data		

direito contratual. (...) Os serviços de educação, sejam os prestados pelo Estado, sejam os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. Nos termos do art. 22, I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre Direito Civil” ■ Trata-se da Lei n. 10.989/93, do Estado de Pernambuco — inconstitucional	■ ADI 1.007, Rel. Min. Eros Grau, j. 1.º.08.2005, Plenário, <i>DJ</i> de 24.02.2006 ■ No mesmo sentido: ADI 1.042, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 12.08.2009, Plenário, <i>DJE</i> de 6.11.2009	■ União — art. 22, I (direito civil) ■ Não se enquadra como “educação” (art. 24, IX) ■ Trata-se de direito civil: “obrigações, contraprestações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais”
■ Lei estadual que regula obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei n. 11.446/97 do Estado de Pernambuco) — inconstitucional	■ ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.02.08.2006, Plenário, <i>DJ</i> de 07.12.2006 ■ Precedente: ADI 1.595, Rel. Min. Eros Grau, j. 03.03.2005, Plenário, <i>DJ</i> de 07.12.2006	■ União — art. 22, I e VII (direito civil, comercial e política de seguros)
■ Lei n. 14.464/2011, do Estado de Pernambuco, que determina prazos		

que determina prazos máximos para a autorização de exames que necessitem de análise prévia, a serem cumpridos pelas empresas de planos de saúde de acordo com a faixa etária do usuário — inconstitucional	■ ADI 4.701, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.08.2014, Plenário, <i>DJE</i> de 25.08.2014	■ União — art. 22, I e VII (direito civil, comercial e política de seguros) ⁶⁵
■ Lei n. 2.149/2009, do Estado do Acre, que permite a comercialização de artigos de conveniência em farmácias e drogarias — constitucional	■ ADI 4.954, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.08.2014, Plenário, <i>DJE</i> de 30.10.2014 ■ No mesmo ano de 2014, o STF enfrentou a mesma matéria em vários outros julgados: ADI 4.093, ADI 4.423, ADI 4.948, ADI 4.949, ADI 4.950, ADI 4.951, ADI 4.952, ADI 4.953, ADI 4.955, ADI 4.956, ADI 4.957	■ Estados — art. 25, § 1.º (competência residual ou remanescente para legislar sobre comércio local. Assim, não se aplica o art. 22, VIII — comércio interestadual) ■ Não se trata de normas gerais de proteção e de defesa da saúde (art. 24, XII) ■ Outro fundamento para alguns Ministros: art. 24, XII (defesa da saúde). Como a lei federal estabeleceu normas gerais apenas sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, nada dispondo

	4.956, ADI 4.957	farmacêuticos e correlatos, nada dispondo sobre a venda de bens de conveniência, os Estados estariam autorizados a legislar em razão da competência suplementar (art. 24, §§ 1.º a 4.º)
■ A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos	■ ADI 2.222, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.11.2011, Plenário, <i>DJ</i> de 07.12.2011 ■ SV 46/STF: “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União” (j. 09.08.2015).	■ União — arts. 22, I (matéria penal e processual) ■ O assunto deve ser tratado em lei nacional especial (art. 85 da CF/88)

■ 7.11. AMIANTO, TABACO E **OUTDOOR**⁶⁵

Resolvemos destacar esses temas. O foco é em relação às leis antifumo como a do Estado de São Paulo (Lei n. 13.541/2009) e a do Rio de Janeiro (Lei n. 5.517/2009). Essa parece ser uma tendência, inclusive mundial.

Quem já não escutou falar de Paris (ou já teve a rica e feliz oportunidade de lá estar), o seu *glamour*, os seus cafês, a sua arte, a sua cultura, o extraordinário

romantismo, o charme dos cafés. Poderíamos ficar aqui por horas falando sobre a encantadora Paris... [66](#)

Pois bem, até Paris “surpreendeu” o mundo ao apresentar ampla aceitação da lei que proibiu o tabaco em bares, restaurantes, discotecas e cassinos do país a partir de janeiro de 2008.

Entendemos que a solução para o caso da lei antifumo poderá seguir a tendência de interpretação que vem sendo adotada pelo STF em relação ao amianto (**matéria pendente**).

■ 7.11.1. Amianto

E em que medida o amianto relaciona-se com Paris e os outros temas?

Também, no Brasil, na tentativa de **proteção à saúde**, várias leis, sejam estaduais, sejam municipais, proíbem o uso do amianto, que é utilizado em alguns produtos, como nas tubulações, telhas, caixas d’água, mangueiras, papéis, papelões etc.

O problema é que existe a Lei federal n. 9.055/95 (Dec. n. 2.350/97), que **admite** o seu **uso controlado**, limitando-o à variedade *crisotila* (asbesto branco).

Dessa forma, o que se sustenta é que as leis estaduais e municipais que proíbem o amianto sem qualquer exceção estariam violando a **regra geral** da lei federal que o admite.

Aliás, vale notar que a referida Lei n. 9.055/95 está sendo questionada na **ADI 4.066**, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Algumas ações, **inicialmente**, foram julgadas procedentes, declarando a **inconstitucionalidade formal orgânica** das leis estaduais ou municipais, sob o argumento de que referidos entes federativos não poderiam violar a regra geral já estabelecida pela lei federal. Vamos a elas:

■ **ADI 2.396** — 08.05.2003: o STF entendeu que o Estado de Mato Grosso do Sul não poderia proibir o uso do amianto (Lei estadual n. 2.210/2001), já que a competência para legislar sobre o assunto é **concorrente** e existe a lei federal admitindo-o — art. 24, V, VI e XII, CF;

■ **ADI 2.656** — 08.05.2003: no mesmo sentido, a Suprema Corte entendeu que a lei paulista (Lei n. 10.813/2001) não poderia ter disciplinado o assunto, violando tanto os citados incisos do art. 24 como, ainda, os arts. 20, IX, e 22, VIII e XII;

ADI 3.356 — 26.10.2005: o relator, Min. Eros Grau, pelos mesmos argumentos (tratar-se de competência concorrente — art. 24, V, VI e XII — e haver lei federal), entendeu que o Estado de Pernambuco (Lei n. 12.589/2004) não poderia ter legislado sobre o assunto. Houve pedido de vista do Min. Joaquim Barbosa e referida ADI ainda não foi julgada (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Essas vinham sendo as decisões do STF, a maioria no sentido de se tratar de competência concorrente (art. 24, V — produção e consumo; VI — meio ambiente e poluição; XII — proteção e defesa da saúde).

Assim, teoricamente, conforme decidiu o STF, havendo a lei federal, os Estados só poderiam legislar suplementando-a, porém, nunca contrariando ou negando o dispositivo. Se a lei federal admite de modo restrito o uso do amianto, teoricamente, a lei estadual ou municipal não poderia proibi-lo totalmente.

Algumas decisões lembraram o art. 20, IX (os recursos minerais como bens da União), e a **competência privativa** da União para legislar sobre comércio interestadual (art. 22, VIII) e sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII).

Então, tentando harmonizar o art. 24, V, VI e XII, de um lado (competência concorrente) e o art. 22, VIII e XII, de outro (competência privativa da União), parece que, apesar de se tratar de competência concorrente (e os Estados poderiam legislar plenamente se não houvesse lei federal), nesse caso do amianto, teoricamente, só existiria a **competência suplementar complementar** e nunca a suplementar supletiva (é uma tentativa de harmonizar a decisão que admitiu os dois dispositivos), já que competiria à União, também, legislar

privativamente sobre o assunto, havendo, assim, uma releitura do art. 24, §§ 1.º a 4.º.

O **STF**, contudo, sinalizou inegável mudança de entendimento em relação ao amianto.

Em 04.06.2008, por 7 x 3, o Pleno, no julgamento da **ADI 3.937**, negou referendo à liminar concedida pelo relator, Min. Marco Aurélio, que declarava inconstitucional a Lei estadual paulista n. 12.684/2007, que proibiu o amianto, seguindo sua Excelência os termos do entendimento anterior fixado na ADI 2.656.

Dessa forma, não referendada a liminar, a lei paulista, que novamente proibiu o amianto, continua vigorando.

Aguarda-se o julgamento de mérito da referida ação, bem como, em conjunto, da **ADI 3.357**, esta tratando da Lei estadual n. 11.643/2001, do Estado do Rio Grande do Sul, também no sentido de proibição do amianto.

Em **31.10.2012**, após o voto do Min. Marco Aurélio (Relator), decidindo pela procedência da ação direta, e o voto do Min. Ayres Britto (Presidente), entendendo-a improcedente, o julgamento (do mérito) foi suspenso (**matéria pendente**). No sentido da constitucionalidade das legislações mais protetivas que proíbem o amianto, salientamos:

■ **Convenção 162 da OIT:** assinada pelo Brasil, recomenda a não pulverização do amianto, desestimulando o seu uso. Por ter, segundo interpretou o STF, natureza **supralegal** (destacando-se o *princípio da prevalência dos direitos humanos*, **art. 4.º, II, da CF/88** — cf. *item 9.14.5.2.3*), paralisaria a eficácia (já que mais protetiva) da lei federal;

■ **Princípio constitucional do direito à saúde:** alguns Ministros concluíram que a utilização do amianto traz riscos à saúde (sustentando, inclusive, o risco de câncer), e, assim, apesar de haver lei federal admitindo o seu uso controlado, a lei do Estado de São Paulo é mais protetiva e, portanto, em uma ponderação de interesses, prevaleceria a proteção à saúde (**arts. 196 e 6.º, caput, da CF/88**). Nesse sentido, o **art. 7.º, XXII, da CF/88** estabelece ser direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

■ **princípios gerais da atividade econômica (consumidor e meio ambiente):** as legislações estaduais, mais protetivas, dentro da ideia de ponderação, amoldam-se melhor aos *princípios da defesa do consumidor* e do *meio ambiente* (art. 170, V e VI, da CF/88);

meio ambiente ecologicamente equilibrado: nos termos do art. 225, *caput*, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cabe lembrar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado integra o **desenvolvimento nacional** (art. 3.º, II). Dessa forma, a legislação que proíbe a utilização de amianto se conforma melhor à Constituição.

Em seu voto, o Min. Ayres Britto assentou: “Lei estadual que, ao proibir a comercialização de produtos à base de amianto, cumpre muito mais a Constituição da República no plano da proteção da saúde (evitar riscos à saúde da população em geral, dos trabalhadores em particular e do meio ambiente). Quero dizer: **a legislação estadual é que está muito mais próxima do sumo princípio da eficácia máxima da Constituição em tema de direitos fundamentais**. Tão mais próxima da Convenção da OIT, acresça-se, quanto o diploma federal dela se distancia” (voto proferido em 31.10.2012).

Na mesma linha de argumentação, o Min. Lewandowski negou, em **22.04.2009**, liminar na **ADPF 109**, que tem por objeto a lei do município de São Paulo n. 13.113/2001, que proíbe a utilização do amianto na construção civil (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

■ 7.11.2. Tabaco

Como se sabe, algumas leis, sejam estaduais, sejam municipais, estão proibindo o uso do tabaco e sendo questionadas no STF:

■ **ADI 4.239** — 12.05.2009: tinha por objeto a *Lei Antifumo do Estado de São Paulo* (Lei n. 13.541, de 07.05.2009). A Min. Ellen Gracie arquivou-a, por entender que a Associação Brasileira de Restaurantes e

Empresas de Entretenimento (Abrasel Nacional), que ajuizou a ação, não se enquadrava no conceito de *entidade de classe de âmbito nacional* (art. 103, IX). A análise foi apenas formal e não sobre o mérito da questão;

■ **ADI 4.249** — 09.06.2009: também tem por objeto a lei paulista. Foi ajuizada pela Confederação Nacional do Turismo (CNTUR), alegando, dentre outros argumentos, o fato de o Estado não poder extrapolar a lei federal que já disciplina o assunto. O AGU, em sua manifestação, argumentou que a Assembleia Legislativa ultrapassou sua competência na medida em que tratou de regras gerais que já estavam na lei federal. À época, o parecer foi dado pelo hoje Min. Dias Toffoli (que era o AGU) e, assim, certamente, no presente caso, ele não poderá votar, devendo declarar-se impedido (**matéria pendente de julgamento pelo STF**);

ADI 4.353 — 07.12.2009: questiona a Lei paranaense n. 16.239/2009, que proíbe o fumo em ambientes coletivos públicos ou privados em todo o Estado do Paraná, tendo sido ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Em 18.12.2009, a Min. Ellen Gracie, relatora, determinou o seu apensamento à **ADI 4.351**, por possuírem o mesmo objeto e, assim, a sua tramitação conjunta (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

De fato, não há dúvida de que a **lei estadual** é muito mais restritiva, inclusive em relação aos direitos individuais dos fumantes, violando a Lei federal n. 9.294/96 que autoriza o **fumódromo** “em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente” (art. 2.º).

Nessa linha, em **23.06.2009**, a Justiça de São Paulo suspendeu parcialmente a Lei Antifumo, concedendo liminar requerida pela Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abresi) (Juiz Valter Alexandre Mena, da 3.^a Vara da Fazenda Pública, autos n. 053.09.015779-9), por conflitar a lei estadual, em alguns pontos, com a lei federal citada, especialmente em relação aos fumódromos e sanções ao empresário. Referida decisão foi cassada pelo TJ/SP.

Diante de todo o exposto, restará ao STF a palavra final.

Entendemos que a lei paulista antifumo apresenta-se na linha do que decidiu o STF no julgamento da medida liminar na ADI 3.937 sobre o amianto (matéria

pendente). A lei paulista é mais protetiva e melhor resguarda o **princípio de proteção à saúde**.

Ainda, o Brasil é signatário da **Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco** (Dec. 5.658/2006) que desestimula o uso do tabaco.

O **tabagismo** caracteriza-se, na atualidade, como a **principal causa de morte evitável** e, portanto, indiscutível ser dever do Estado (e de seus entes federativos) proteger a saúde e, assim, combater o fumo que, quando consumido, introduz no organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, destacando-se a **nicotina** (responsável pela combatida e famigerada dependência química), o **monóxido de carbono** (gás) e o **alcatrão** (que contém substâncias pré-cancerígenas), sem contar a problemática do **fumante passivo**.

A lei paulista mostra-se bastante “corajosa” e, em nosso entender, conforma-se melhor à Constituição. O direito individual de fumar não está sendo proibido, mas apenas restringido (de maneira bastante **enérgica**, reconheça-se, mas não inconstitucional).

■ 7.11.3. *Outdoor* — “Lei Cidade Limpa”

Em igual medida, parece caminhar a questão colocada em relação à denominada “Lei Cidade Limpa” no Município de São Paulo que proibiu, dentre outras coisas, a utilização do *outdoor* (sobre o tema, cf. *Suspensão Liminar 161 e Reclamação 7781*) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

■ 7.12. INTERVENÇÃO

Como já tivemos oportunidade de alertar, o art. 18, *caput*, da CF/88 preceitua que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**, nos termos da Constituição Federal.

No entanto, excepcionalmente, a CF prevê situações (de anormalidade) em que haverá intervenção, suprimindo-se, temporariamente, a aludida autonomia.

As hipóteses, por trazerem regras de anormalidade e exceção, devem ser interpretadas restritivamente, consubstanciando-se um rol taxativo, *numerus clausus*.

A regra da intervenção seguirá o seguinte esquema:

■ **Intervenção federal:** União nos Estados, Distrito Federal (hipóteses do art. 34) e nos Municípios localizados em território federal (hipótese do art. 35);

Intervenção estadual: Estados em seus Municípios (art. 35).

Conforme observa Humberto Peña de Moraes, em brilhante estudo, sendo “instituto típico da estrutura do Estado Federal, repousa a intervenção no afastamento temporário da atuação autônoma da entidade federativa sobre a qual a mesma se projeta”.⁶⁷

■ 7.12.1. Intervenção federal

■ 7.12.1.1. Hipóteses de intervenção federal

As hipóteses de **intervenção federal** (e quando dizemos intervenção federal significa intervenção realizada pela União)⁶⁸ nos **Estados** e no **Distrito Federal** estão taxativamente previstas no art. 34, sendo cabíveis para:

manter a integridade nacional;

repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;

pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;

garantir o livre-exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

reorganizar as finanças da unidade da Federação que: *a)* suspender o pagamento da dívida fundada⁶⁹ por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; *b)* deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

reorganizar as finanças da unidade da Federação que: *a)* suspender o pagamento da dívida fundada [69](#) por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; *b)* deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: *a)* forma republicana, sistema representativo e regime democrático; *b)* direitos da pessoa humana; *c)* autonomia municipal; *d)* prestação de contas da Administração Pública, direta e indireta; *e)* aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. [70](#)

As hipóteses de **intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais** serão estudadas quando tratarmos da *intervenção estadual*, prevista no art. 35.

■ 7.12.1.2. *Espécies de intervenção federal*

■ **espontânea:** nesse caso o Presidente da República age de ofício art. 34, I, II, III e V;

■ **provocada por solicitação:** art. 34, IV, combinado com o art. 36, I, primeira parte quando coação ou impedimento recaírem sobre o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, impedindo o livre-exercício dos aludidos Poderes nas unidades da Federação, a decretação da intervenção federal, pelo Presidente da República, dependerá de **solicitação** do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido;

provocada por requisição: *a)* art. 34, IV, combinado com o art. 36, I, segunda parte se a coação for exercida contra o **poder judiciário**, a decretação da intervenção federal dependerá de **requisição** do Supremo Tribunal Federal; *b)* art. 34, VI, segunda parte, combinado com o art. 36, II no caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, a decretação dependerá de **requisição** do STF, do STJ ou do TSE, de acordo com a matéria;

intencional e haver recursos financeiros (cf. discussão no *item 11.12.11*).

■ **provocada, dependendo de provimento de representação:** a) art. 34, VII, combinado com o art. 36, III, primeira parte no caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, previstos no art. 34, VII, da CF/88, a intervenção federal dependerá de **provimento**, pelo **STF, de representação do Procurador-Geral da República** (representação interventiva, conforme expusemos no capítulo sobre controle, *item 6.7.5.2*); b) art. 34, VI, primeira parte, combinado com o art. 36, III, segunda parte para prover a execução de lei federal (pressupondo ter havido recusa à execução de lei federal), a intervenção dependerá de **provimento de representação** do procurador-Geral da República pelo **STF (EC n. 45/2004)** (trata-se, também, de representação interventiva, regulamentada pela **Lei n. 12.562/2011** e com as explicitações nos *itens 6.7.5.2.5 e 6.7.5.2.7* desse trabalho).

Quanto a esta última hipótese, Humberto Peña de Moraes observa: “insista-se, por oportuno, que a *actio* vertente não busca alcançar oportuna declaração de inconstitucionalidade — fim a que se propõe a ação direta de inconstitucionalidade interventiva — com vista a possível intervenção, mas sim a garantir, ocorrendo recusa por parte de Estado ou do Distrito Federal e julgada procedente a pretensão pela Excelsa Corte, a execução de lei federal, sob pena, é óbvio, da prática interventiva. A intervenção para execução de lei federal só deve ser havida por lícita, insta observar, quando não existir outro tipo de ação aparelhada para a solução da *quaestio juris*”.⁷¹

Na hipótese de **solicitação** pelo Executivo ou Legislativo, o Presidente da República não estará obrigado a intervir, possuindo **discrecionariiedade** para convencer-se da **conveniência** e **oportunidade**. Por outro lado, havendo **requisição** do Judiciário, não sendo o caso de suspensão da execução do ato impugnado (art. 36, § 3.º), o Presidente da República estará **vinculado** e deverá decretar a intervenção federal, sob pena de responsabilização.

■ 7.12.1.3. Decretação e execução da intervenção federal

Como vimos, a decretação e execução da intervenção federal é de competência privativa do **Presidente da República** (art. 84, X), dando-se de forma espontânea ou provocada. Lembramos, ainda, a previsão da oitiva de dois órgãos superiores de consulta, quais sejam, o *Conselho da República* (art. 90, I) e o *Conselho de Defesa Nacional* (art. 91, § 1.º, II), sem haver qualquer vinculação do Chefe do Executivo aos aludidos pareceres.

A decretação materializar-se-á por **decreto presidencial de intervenção**, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e, quando couber, nomeará o interventor.

■ 7.12.1.4. Controle exercido pelo Congresso Nacional

Nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 36, o **Congresso Nacional (Legislativo)** realizará **controle político** sobre o decreto de intervenção expedido pelo **Executivo** no prazo de 24 horas, devendo ser feita a convocação extraordinária, também no prazo de 24 horas, se a Casa Legislativa estiver em recesso parlamentar. Assim, nos termos do art. 49, IV, o **Congresso Nacional** ou **aprovará** a intervenção federal ou a **rejeitará**, sempre por meio de **decreto legislativo**, suspendendo a execução do decreto interventivo nesta última hipótese.

Em caso de rejeição pelo Congresso Nacional do decreto interventivo, o Presidente da República deverá cessá-lo imediatamente, sob pena de cometer crime de responsabilidade (art. 85, II — atentado contra os Poderes constitucionais do Estado), passando o ato a ser inconstitucional.

■ 7.12.1.4.1. Hipóteses em que o controle exercido pelo Congresso Nacional é dispensado

Como regra geral, o decreto interventivo deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional (controle político). Excepcionalmente, a CF (art. 36, § 3.º) dispensa a aludida apreciação, sendo que o decreto se limitará a suspender a execução do

ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. As hipóteses em que o controle político é dispensado são as seguintes:

■ **art. 34, VI** para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

art. 34, VII quando houver afronta aos princípios sensíveis da CF.

Nesses casos, no entanto, se o decreto que suspendeu a execução do ato impugnado **não foi suficiente para o restabelecimento da normalidade**, o Presidente da República **decretará a intervenção federal**, nomeando, se couber, interventor, devendo submeter o seu ato ao exame do Congresso Nacional (**controle político**), no prazo de 24 horas, nos termos do art. 36, § 1.º, conforme referido.

■ **7.12.1.5. Afastamento das autoridades envolvidas**

Por meio do **decreto interventivo**, que especificará a amplitude, prazo e condições de execução, o Presidente da República nomeará (quando necessário) interventor, afastando as autoridades envolvidas.

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal (art. 36, § 4.º).

■ **7.12.2. Intervenção estadual**

■ **7.12.2.1. Hipóteses de intervenção estadual e intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais**

As hipóteses de **intervenção estadual** e **federal** (nos Municípios localizados em Territórios Federais) estão taxativamente previstas no art. 35, sendo cabíveis quando:

deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;[72](#)
o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

■ 7.12.2.2. *Decretação e execução da intervenção estadual*

A decretação e execução da intervenção estadual é de competência privativa do **Governador de Estado**, por meio de **decreto de intervenção**, que especificará a amplitude, o prazo e as condições da execução e, quando couber, nomeará o interventor.

■ 7.12.2.3. *Controle exercido pelo legislativo*

A Constituição estabeleceu a realização de **controle político** a ser exercido pelo Legislativo, devendo o decreto de intervenção ser submetido à apreciação da **Assembleia Legislativa**, no prazo de 24 horas. Na hipótese de não estar funcionando, haverá convocação extraordinária, também no prazo de 24 horas.

■ 7.12.2.3.1. *Hipóteses em que o controle exercido pela Assembleia Legislativa é dispensado*

Em regra, o decreto interventivo deverá ser apreciado pela Assembleia Legislativa (intervenção estadual). Excepcionalmente, porém, a CF (art. 36, § 3.º) dispensa a aludida apreciação pelo Congresso Nacional (hipóteses já estudadas quando tratamos da intervenção federal), ou pela Assembleia Legislativa estadual, sendo que o decreto, nesses casos, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. A hipótese em que o controle político é dispensado ocorre quando:

■ **art. 35, IV** o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

No entanto, se a suspensão da execução do ato impugnado não for suficiente para o restabelecimento da normalidade, o Governador de Estado decretará a intervenção no Município (hipótese de intervenção estadual em Município), submetendo esse ato (decreto interventivo) à Assembleia Legislativa, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente.

■ **7.12.2.4. Afastamento das autoridades envolvidas**

No decreto interventivo que especificará a amplitude, prazo e condições de execução, o Governador de Estado nomeará (quando necessário) interventor, afastando as autoridades envolvidas.

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal (art. 36, § 4.º).

■ **7.12.2.5. Súmula 637 do STF**

Nos termos da S. 637/STF, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município”.

■ **7.13. QUESTÕES**

■ **7.13.1. Federação: aspectos conceituais**

1. (OAB/101.%/SP) Só uma das alternativas não caracteriza a Federação:

- a) subordinação financeira dos Estados à União em nome da unidade nacional;
- b) descentralização político-administrativa constitucionalmente prevista;
- c) existência de um órgão que dite a vontade dos Estados-Membros da Federação, no caso

o Senado Federal;

- d) existência de um órgão constitucional encarregado do controle da constitucionalidade das leis, dificultando a invasão de competência.

2. (Magistratura MG — 2004/2005) Pela Constituição de 1988, a federação brasileira é constituída pela união indissolúvel:

- a) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- b) da União, Estados e Distrito Federal.
- c) da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios.
- d) da União, Estados e Municípios.
- e) da União, Estados, Distrito Federal e Territórios.

3. (OAB/102.º/SP) Podem ser divididos em Municípios:

- a) Estados, Distrito Federal e territórios;
- b) Estados e Distrito Federal;
- c) Estados e Territórios;
- d) apenas os Estados.

4. (Magistratura/172.º) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão:

- a) por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos;
- b) por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar estadual, após consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, desde que referendado o resultado daquele pelas Câmaras Municipais desses Municípios;
- c) por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar estadual, após consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, desde que referendado o resultado daquele pelo Executivo e pelo Legislativo desses municípios;
- d) por lei federal, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos.

5. (Acadepol 2006 — UFA) Com relação à organização político-administrativa do

Estado Brasileiro, marque a alternativa correta.

- a) A fusão de Municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei ordinária federal, e dependente de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos no processo.
- b) Os Estados-membros não podem recusar fé aos documentos públicos da União, facultando-se-lhes, porém, recusar o reconhecimento de documentos de outros Estados.
- c) Nos Territórios Federais, com mais de duzentos mil habitantes, além do Governador, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instâncias e membros do Ministério Público.
- d) Enquanto unidade federada com autonomia parcialmente tutelada, o Distrito Federal possui somente competência legislativa estadual.
- e) A União é pessoa jurídica de direito público interno com capacidade política, e ora se manifesta em nome próprio, ora se manifesta em nome da Federação.

6. (Diplomata CESPE/UnB — 2009) Acerca do Estado federal brasileiro e do sistema de repartição de competências entre os entes federativos, julgue (C ou E) o próximo item:

O Estado federal brasileiro — a República Federativa do Brasil — é pessoa jurídica de direito público internacional, e sua organização político-administrativa compreende a União, os estados e o Distrito Federal, mas não os municípios, pois estes não são entidades federativas, visto que constituem divisões político-administrativas dos estados.

7. (AGU/CESPE-UnB — 2008) No tocante às hipóteses de alteração da divisão interna do território brasileiro, é correto afirmar que, na subdivisão, há a manutenção da identidade do ente federativo primitivo, enquanto, no desmembramento, tem-se o desaparecimento da personalidade jurídica do estado originário.

8. (MP RN-CESPE/UnB — 2009) Assinale a opção correta com relação ao federalismo brasileiro:

- a) O federalismo brasileiro, quanto à sua origem, é um federalismo por agregação.
- b) Existia no Brasil um federalismo de segundo grau até a promulgação da CF, após a qual o país passou a ter um federalismo de terceiro grau.
- c) Uma das características comuns à federação e à confederação é o fato de ambas serem

- a) O federalismo brasileiro, quanto à sua origem, é um federalismo por agregação.
- b) Existia no Brasil um federalismo de segundo grau até a promulgação da CF, após a qual o país passou a ter um federalismo de terceiro grau.
- c) Uma das características comuns à federação e à confederação é o fato de ambas serem indissolúveis.
- d) A federação é o sistema de governo cujo objetivo é manter reunidas autonomias regionais.
- e) Os territórios federais são considerados entes federativos.

9. (Procurador do Estado do Amazonas/FCC/2010) De acordo com a Constituição Federal, os Territórios:

- a) integram a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, juntamente com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos da Constituição.
- b) podem integrar a União ou os Estados, conforme dispuser a lei complementar que os criar.
- c) gozam de autonomia organizacional, uma vez que lhes cabe instituir sua própria lei orgânica.
- d) podem ser subdivididos em Municípios.
- e) gozam de autonomia política, uma vez que elegem seu próprio governador.

10. (XXXII MP/RJ — 2011) A regra constitucional que admite o desmembramento de Estados depende da aprovação da população diretamente interessada, entendida como tal a população:

- a) tanto da área desmembrada do Estado-membro como a da área remanescente, mediante referendo.
- b) da área desmembrada do Estado-membro, mediante referendo.
- c) da área desmembrada do Estado-membro, mediante referendo, bem como de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional.
- d) tanto da área desmembrada do Estado-membro como a da área remanescente, mediante plebiscito, bem como de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional.
- e) da área desmembrada do Estado-membro, mediante plebiscito, bem como de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional.

ESAF/2013) Quanto à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que:

- a) para fins de desmembramento de um Estado, deve haver consulta prévia à população diretamente interessada, compreendendo esta somente a população da área a ser destacada.
- b) o Poder Constituinte derivado-decorrente deve respeitar os princípios constitucionais sensíveis, os princípios federais extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos.
- c) as competências administrativas dos Municípios são residuais, ou seja, lhes compete aquilo que não for das áreas administrativas dos Estados e da União.
- d) a competência da União para legislar sobre normas gerais e dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre normas específicas é chamada competência legislativa concorrente e compreende, entre outras matérias, orçamento, juntas comerciais, direito tributário e registros públicos.
- e) a União poderá, por meio de lei ordinária, delegar aos Estados e ao Distrito Federal questões específicas acerca das matérias de sua competência legislativa privativa.

13. (Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes — Estradas — DNIT — ESAF/2013) Em relação à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, é correto afirmar que:

- a) estão entre as matérias de competência legislativa privativa da União desapropriação, registros públicos, propaganda comercial, juntas comerciais e proteção à infância e à juventude.
- b) são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
- c) estão entre as matérias de competência legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios orçamento, procedimento em matéria processual, desapropriação e trânsito e transporte.
- d) compete aos Municípios e ao Distrito Federal explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei.
- e) ao Distrito Federal são atribuídas as competências reservadas aos Estados e aos Municípios, inclusive organizar e manter o seu Ministério Público e o seu Poder Judiciário.

14. (Câmara dos Deputados — Analista Legislativo — CESPE/UnB/2012) Com relação

à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o próximo item:

Os territórios federais integram, na qualidade de entes federativos, a estrutura político-administrativa do Brasil.

15. (Analista Administrativo — ANATEL — CESPE/UnB/2012) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o próximo item:

A cidade de Brasília é a Capital Federal, sendo vedada pela Constituição Federal a transferência da sede do governo federal para outra cidade.

16. (Agente Administrativo — TCE-RO — CESPE/UnB/2013) Acerca da organização do Estado e da organização do poder estabelecida na CF, julgue o seguinte item:

Brasília está localizada no Distrito Federal, mas não se confunde com ele. A Capital Federal não possui autonomia. De acordo com a CF, a autonomia é uma característica do Distrito Federal, dos municípios, dos Estados-membros e da União.

■ 7.13.2. Federação: intervenção

1. (OAB/116.º/SP) A União, por decreto, interveio em estado-Membro, em face do descumprimento de decisão judicial (relativa ao pagamento de precatório). Posto isto:

- a) o decreto de intervenção deve ser submetido ao Congresso Nacional, no prazo de 24 horas;
- b) poderá o Congresso aprovar emenda constitucional para modificar o art. 100 da Constituição Federal (ordem de pagamento dos precatórios);
- c) deve a União submeter o decreto da intervenção ao Supremo Tribunal Federal;
- d) o decreto de intervenção poderá limitar-se à suspensão da execução do ato impugnado.

2. (Delegado de Polícia/RJ/CEPERJ — 2009) Qual das situações abaixo não constitui causa de intervenção da União nos Estados ou no Distrito Federal:

- a) Manter a integridade nacional.
- b) Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outras.
- c) Garantir o livre-exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.
- d) Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
- e) Violar as regras do sistema financeiro nacional.

3. (Magistratura/173.º) Assinale a alternativa correta: a intervenção em município, desde que verificada uma das hipóteses que a possibilitem, compete:

- a) à União;
- b) ao Estado em cujo território se localiza;
- c) ao Supremo Tribunal Federal, se localizado em Território Federal;
- d) à União e ao Estado em cujo território se localiza, concorrentemente.

4. (MPT/2006) Assinale a alternativa correta. A decretação de intervenção da União nos Estados dependerá:

- a) de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, na hipótese de repelir invasão de uma unidade da Federação em outra;
- b) de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, no caso de recusa à execução de lei federal;
- c) de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Superior do Trabalho, no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial;
- d) de requisição do Supremo Tribunal Federal, para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas da administração pública, direta e indireta; aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
- e) não respondida.

5. (Analista do MPSE — Área Direito — FCC/2010) São causas, dentre outras, que justificam a intervenção federal, a necessidade de reorganizar as finanças de Estado-membro que suspende o pagamento da dívida fundada por

- a) 1 (um) ano, salvo impossibilidade orçamentário-financeira; e repelir invasão de uma unidade da Federação em um Município.
- b) mais de 2 (dois) anos consecutivos, salvo motivo de força maior; e repelir invasão de uma unidade da Federação em outra.
- c) até 2 (dois) anos consecutivos, em qualquer hipótese; e por termo a comprometimento da ordem pública.
- d) mais de 3 (três) anos consecutivos, ou não, em qualquer hipótese; e prover à execução

de lei federal ou estadual.

- e) até 1 (um) ano, salvo motivo de força maior ou caso fortuito; e para prover execução de decisão judicial ou administrativa.

6. (Procurador Jurídico da USP/FUVEST — 2011) A intervenção federal nos Estados, no caso de desobediência de ordem ou decisão judiciária:

- a) é vedada, exceto na hipótese de violação dos chamados princípios sensíveis, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de representação proposta pelo Procurador-Geral da República.
- b) não cabe ser requisitada de ofício pelo órgão judicial competente, mas apenas mediante pedido de Presidente de Tribunal de Justiça do Estado ou Presidente de Tribunal Federal.
- c) não cabe ser requisitada de ofício pelo órgão judicial competente, mas apenas mediante pedido da parte prejudicada em face da desobediência da ordem ou decisão judicial.
- d) depende de requisição do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, com exceção do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar.
- e) cabe ser requisitada pelo Supremo Tribunal de Justiça, caso a decisão ou ordem a ser provida não tenha fundamento em preceito constitucional, mas, sim, em qualquer dispositivo constante da legislação federal.

7. (Analista de Controle Externo — TCE/AM — FCC/2012) A intervenção do Estado-membro em Município é medida excepcionalmente autorizada pela Constituição Federal, que pode ser tomada, entre outras hipóteses, quando:

- a) o Prefeito Municipal for condenado, por decisão judicial transitada em julgado, em ação civil por improbidade administrativa.
- b) o Prefeito Municipal for condenado pela prática de crime de responsabilidade, por decisão judicial transitada em julgado.
- c) não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
- d) houver conflito relevante entre Estado e Município que possa comprometer o equilíbrio federativo.
- e) o Tribunal Regional Federal der provimento a representação para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial.

8. (Comissário da Infância e da Juventude — TJ-RJ — FCC/2012) Na hipótese de um Estado-membro da Federação deixar de aplicar o mínimo exigido da receita

resultante de impostos estaduais, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, prevê a Constituição da República que:

- a) a União poderá intervir no Estado, sendo o decreto de intervenção submetido à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de vinte e quatro horas.
- b) a União poderá decretar intervenção federal no Estado, para reorganizar as finanças do ente da federação, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal.
- c) o Estado ficará sujeito à intervenção federal, cuja decretação dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
- d) a União poderá intervir no Estado, mediante solicitação do Poder Legislativo estadual, a fim de garantir o livre-exercício dos poderes na unidade da Federação.
- e) o Tribunal de Justiça deverá dar provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição estadual.

9. (Auditor Fiscal da Receita Estadual — SEFAZ/RJ — FCC/2014) Suponha que o Presidente da República esteja obstruindo o livre-exercício das atividades do Congresso Nacional. Neste caso:

- a) a União poderá sofrer intervenção federal mediante requisição do Senado Federal.
- b) a União poderá sofrer intervenção federal por solicitação do Congresso Nacional.
- c) o Presidente da República poderá ser submetido a julgamento, perante o Senado Federal, por crime de responsabilidade.
- d) a União poderá sofrer intervenção federal mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
- e) o Presidente da República poderá ser submetido a julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade.

■ 7.13.3. Federação: competência

1. (OAB/110.º/SP) Sobre a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, é correto dizer que:

- a) a lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal;
- b) a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual, no que lhe for contrário;

- c) a União, os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a editar normas gerais e específicas para atender suas respectivas peculiaridades;
- d) na falta de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades.

2. (Magistratura/173.º) Assinale a incorreta: no âmbito da legislação concorrente da União, Estados e Distrito Federal:

- a) a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais;
- b) a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados;
- c) a superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário;
- d) à falta de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades.

3. (Magistratura/168.º/SP) Legislar sobre custas dos serviços forenses é competência:

- a) privativa da União;
- b) privativa dos Municípios;
- c) concorrente da União, Estados e Distrito Federal;
- d) privativa dos Estados.

4. (MP/81.º/SP) Indique a alternativa em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente sobre todas as matérias agrupadas:

- a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; procedimentos em matéria processual; proteção à infância e à juventude;
- b) direito agrário, financeiro, aeronáutico, econômico e urbanístico; trânsito e transporte; custas dos serviços forenses, produção e consumo;
- c) direito tributário, do trabalho, financeiro, econômico e urbanístico; orçamento; juntas comerciais;
- d) desapropriação; trânsito e transporte, juntas comerciais;
- e) seguridade social; proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular.

5. (MP/79.º/SP) Constitui competência privativa da União legislar sobre:

- a) águas, energia e trânsito;
- b) direito econômico, águas e energia;
- c) previdência social, direito econômico e águas;
- d) trânsito, previdência social e direito econômico;
- e) energia, trânsito e previdência social.

6. (OAB/109.º/SP) Lei estadual autoriza menor de 18 anos a usar e conduzir veículo automotor. Esta lei:

- a) é inconstitucional, porque nos termos do art. 23, XII, da CF, União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência comum para estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito;
- b) é inconstitucional, porque a União tem competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte;
- c) é inconstitucional, porque cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local;
- d) é inconstitucional, porque a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados.

7. (Magistratura/167.º/SP) Compete privativamente à União legislar sobre:

- a) produção e consumo;
- b) propaganda comercial;
- c) juntas comerciais;
- d) educação, cultura, ensino e desporto.

8. (OAB/111.º/SP) Em face da distribuição constitucional de competências, a lei estadual que, porventura, discipline a prática de atividades nucleares específicas no respectivo Estado, deve ser considerada:

- a) inconstitucional, visto ser competência da União legislar sobre “atividades nucleares de qualquer natureza”;
- b) constitucional, por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente;
- c) inconstitucional, pois a exploração dos serviços e instalações nucleares é de competência exclusiva da União;
- d) constitucional, desde que o Estado tenha sido autorizado, por lei complementar da União, a legislar sobre tal matéria.

- a) inconstitucional, visto ser competência da União legislar sobre “atividades nucleares de qualquer natureza”;
- b) constitucional, por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente;
- c) inconstitucional, pois a exploração dos serviços e instalações nucleares é de competência exclusiva da União;
- d) constitucional, desde que o Estado tenha sido autorizado, por lei complementar da União, a legislar sobre tal matéria.

9. (OAB/116.º/SP) Quando o Município legisla sobre transporte coletivo municipal de passageiros, está:

- a) suplementando a legislação do Estado;
- b) suplementando a legislação da União, no que couber;
- c) expedindo norma fulcrada em sua própria autonomia;
- d) expedindo normas de sua competência residual.

10. (MP/SP 2006) Assinale a alternativa correta. Compete privativamente à União:

- a) Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
- b) Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
- c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
- d) Legislar sobre trânsito e transporte.
- e) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

11. (TJ/DF 2007) A repartição de competências prevista na Constituição permite afirmar que:

- a) a delegação de competência da União aos Estados-membros opera-se por meio de lei ordinária específica;
- b) não há hierarquia entre os entes da Federação, podendo-se reconhecer preponderância de interesse mais abrangente;
- c) a competência da União para editar normas gerais determina a revogação da norma estadual previamente editada que contrarie a disciplina federal;
- d) a competência dos Municípios para legislar sobre horário de funcionamento de

polícias civil e militar do Distrito Federal.

- c) A competência concorrente sobre as matérias enumeradas na Constituição Federal abrange a União, os Estados e Distrito Federal, excluídos os Municípios.
- d) Os Estados poderão ter competência para certos assuntos quando delegados pela União, porém sobre questões específicas das matérias da competência federal privativa.
- e) Os Municípios têm competência suplementar para suprir lacunas da legislação federal e estadual, mas sem contraditá-las, e competência exclusiva para assuntos de interesse local.

13. (MPE/PR-2008) Compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre (assinale a alternativa correta):

- a) Orçamento, produção e consumo, previdência social e serviço postal;
- b) Desapropriação, telecomunicações, orçamento e custas dos serviços forenses;
- c) Proteção à infância e à juventude, ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
- d) Procedimentos em matéria processual, proteção e defesa da saúde, política de crédito e serviço postal;
- e) Águas, energia, juntas comerciais e orçamento.

14. (DP/ES — CESPE/UnB-2009) Suponha que um Estado-membro da Federação tenha legislado, de forma exaustiva, acerca de assistência jurídica e defensoria pública, dada a inexistência de legislação federal sobre o tema. Nesse caso, ao ser promulgada legislação federal a esse respeito, as normas estaduais incompatíveis com ela serão automaticamente revogadas.

15. (MP PR/2009) Compete privativamente à União legislar sobre:

- a) proteção à infância e juventude;
- b) direito financeiro;
- c) produção e consumo;
- d) registros públicos;
- e) proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

16. (Agente Técnico Legislativo — Direito — FCC/2010) No âmbito da legislação concorrente, conforme a estrutura federativa brasileira:

- a) são reservadas aos Municípios as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição, ditas competências remanescentes.
- b) inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades.
- c) compete aos Estados legislar sobre assuntos de interesse local.
- d) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
- e) a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados e dos Municípios.

17. (Analista MP/SP — Vunesp/2010 — 1.ª fase) No tocante à repartição de competências no Estado Brasileiro, a Constituição Federal estabelece como competência concorrente da União, do Distrito Federal e dos Estados legislar sobre:

- a) serviço postal.
- b) águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
- c) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.
- d) populações indígenas.
- e) custas dos serviços forenses.

18. (Exame da OAB Unificado 2010.2 — FGV) Um determinado Estado-membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino sediadas no seu território. Examinada a questão à luz da partilha de competência entre os entes federativos, é correto afirmar que:

- a) mensalidade escolar versa sobre direito obrigacional, portanto, de natureza contratual, logo cabe à União legislar sobre o assunto.
- b) a matéria legislada tem por objeto prestação de serviço educacional, devendo ser considerada como de interesse típico municipal.
- c) por versar o conteúdo da lei sobre educação, a competência do Estado-membro é concorrente com a da União.
- d) somente competirá aos Estados-membros legislar sobre o assunto quando se tratar de mensalidades cobradas por instituições particulares de Ensino Médio.

19. (XXXII MP/RJ — 2011) A alternativa que inclui em seu rol competência legislativa não privativa da União é:

- a) desapropriação; requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
- b) sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; comércio exterior e interestadual.
- c) sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; sistemas de consórcios e sorteios e propaganda comercial.
- d) águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
- e) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, tributário, financeiro, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

20. (Analista Administrativo — ANAC — Conhecimentos Básicos — CESPE/UnB/2012) Julgue o próximo item, relativo à organização político-administrativa do Estado brasileiro:

Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea.

21. (Analista Judiciário — TRT10 — CESPE/UnB/2013) Com referência à organização político-administrativa brasileira, julgue o próximo item:

Os Estados possuem competência legislativa suplementar em matéria de direito do trabalho, observadas as normas gerais estabelecidas pela União.

22. (Procurador do TCDF — CESPE/UnB/2013) Acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir:

A União, dentro do seu juízo discricionário, pode delegar, por meio de lei específica, assuntos de sua competência legislativa privativa a determinado Estado da Federação, sem necessidade de estender essa delegação a todos os estados.

23. (Procurador da República — MPF — 26.º Concurso/2012) Do enunciado abaixo (marque certo ou errado) (questão adaptada — original com 3 enunciados e 4 alternativas):

Em sede de competência legislativa concorrente, é permitido à lei estadual estabelecer cautelas mais rigorosas, em matéria de saúde e de meio ambiente, do que aquelas contidas na lei federal.

24. (Auditor Fiscal da Receita Estadual — SEFAZ/RJ — FCC/2014) Considere as proposições abaixo, relacionadas ao tema das competências no Federalismo brasileiro:

- I. A União tem competência legislativa privativa em matéria de nacionalidade, cidadania e naturalização, mas os Estados poderão legislar sobre questões específicas relacionadas a estes temas mediante autorização por lei complementar.
- II. A competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico não pode ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e tampouco aos Municípios.
- III. A competência legislativa da União em matéria de educação, cultura, ensino e desporto está limitada ao estabelecimento de normas gerais.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) II e III, apenas.

■ **GABARITO** ■

■ 7.13.1. Federação: aspectos conceituais
1. “a”. Observar que entre as autonomias que garantem a Federação está, justamente, a autonomia financeira, materializada pela cobrança de tributos etc.
2. “a”. Arts. 1.º, <i>caput</i> , e 18, <i>caput</i> .
3. “c”. Observar que o art. 32, <i>caput</i> , expressamente veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, não havendo essa vedação para Estados e Territórios (estes, lembrem-se, apesar de não existirem hoje, podem vir a ser criados e, sendo criados, divididos em Municípios).
4. “a”. De acordo com o art. 18, § 4.º, da CF/88, com a redação dada pela EC n. 15/96.

5. “e”.
6. “errado”.
7. “errado”. Cf., na parte teórica, <i>item 7.5.1.3</i> .
8. “b”. Com o máximo respeito, segundo o entendimento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho (<i>item 7.3.2.7</i>), o texto de 1988 consagra o federalismo de 2.º grau, apesar de se reconhecerem 3 ordens distintas (União, Estados e Municípios), bem como o DF em posição peculiar. Isso porque, exercendo o seu poder de auto-organização, deverá observar os preceitos da Constituição Federal, assim como os da Constituição do respectivo Estado. A <i>letra “a”</i> está errada, pois o federalismo brasileiro implementou-se por desagregação. A <i>letra “c”</i> está errada, porque, diferentemente da Federação, na Confederação se reconhece o direito de segregação (separação do pacto confederativo). A <i>letra “d”</i> está errada, uma vez que Federação não é sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo), mas forma de Estado. Por fim, a <i>letra “e”</i> está errada, pois os Territórios Federais, se criados, não terão autonomia federativa, sendo meras autarquias, uma extensão da União.
9. “d”. Cf. art. 33, § 1.º.
10. “d”. Cf. art. 18, § 3.º, e interpretação jurisprudencial, conforme apontado na parte teórica.
11. “errado”, por violar o art. 22, XVII, que estabelece a competência privativa da União.
12. “b”, cf. <i>item 4.5.3</i> .
13. “b”, de acordo com o art. 26, I. A <i>letra a</i> está errada por violar o art. 24, XV. A <i>letra c</i> viola o art. 22, II e XI. A <i>letra d</i> viola o art. 25, § 2.º, por se tratar de competência estadual. A <i>letra e</i> viola o art. 21, XIII. Mais um típico modelo de questão que exige o conhecimento da literalidade da Constituição!
14. “errado”.
15. “errada”. A primeira parte da afirmação está <i>parcialmente</i> correta, nos termos do art. 18, § 1.º. Entendemos <i>parcialmente</i> , na medida em que se afirma ser Brasília uma cidade. Conforme vimos, Brasília não se enquadra no conceito geral de cidades. A parte final, contudo, viola frontalmente a regra contida no art. 48, VII, da CF/88, que permite essa transferência. Mas

deveria, também, a afirmação ter deixado claro que essa transferência deve ser temporária e por lei do Congresso Nacional. Cf. parte teórica, <i>item 7.4.1</i> .
16. “certo”. Art. 18, § 1.º, e parte teórica (<i>item 7.4.1</i>).
■ 7.13.2. Federação: intervenção
1. “a”. De acordo com os arts. 34, 36, § 3.º, e 84, X, o decreto interventivo é ato exclusivo do Chefe do Executivo. Em determinados casos, porém, antes de decretar a intervenção federal, o Presidente da República limita-se a suspender a execução do ato impugnado (hipóteses dos arts. 34, VI e VII). Caso essa medida não seja eficiente para o restabelecimento da normalidade, o Presidente, então, decreta a intervenção federal, submetendo este segundo ato à apreciação do Congresso Nacional. Na medida em que a questão em análise relata o fato de já ter havido a intervenção federal no Estado, por meio de decreto interventivo, pressupõe-se a prévia tentativa de suspensão do ato impugnado com o objetivo de se restabelecer a normalidade. Como ineficaz essa medida (tendo em vista o enunciado da questão), o decreto de intervenção necessariamente deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo (controle político). Entendemos inconveniente esse formato de questão, pois pode confundir, e muito, o aluno preparado e que sabe a matéria!
2. “e”. Art. 34, I, II, IV e VI, da CF/88.
3. “b”. Cf. art. 35. Lembramos que o decreto interventivo ou de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, é de competência do Chefe do Executivo. No caso, em se tratando de intervenção do Estado em seu Município, a competência será do Governador de Estado.
4. “b”. Art. 36, III, da CF/88.
5. “b”. Art. 34, II e V, “a”, da CF/88.
6. “d”.
7. “c”.
8. “c”. Trata-se de representação interventiva, prevista no art. 34, VII, “e”, e procedimento fixado no art. 36, III, primeira parte, por ofensa a um dos princípios sensíveis.

9. “c”. Questão interessante: conforme vimos, a União não sofre intervenção federal. A União é quem intervirá (art. 34, <i>caput</i>). Portanto, o instituto não é o da intervenção. Assim, a hipótese é de <i>impeachment</i>, nos termos do art. 85, II, cuja competência de julgamento é do SF, e não do STF.
■ 7.13.3. Federação: competência
1. “d”. De acordo com o art. 24, § 3.º. Lembrar que no caso da alternativa “b”, a superveniência de lei federal sobre normas gerais não revoga a lei estadual, mas apenas suspende a sua eficácia, no que lhe for contrário, de acordo com o § 4.º do art. 24. No tocante à alternativa “c”, lembrar que a competência da União se limita a estabelecer apenas normas gerais (art. 24, § 1.º) e não específicas, no âmbito da legislação concorrente.
2. “c”. Cf. art. 24, §§ 1.º a 4.º. Procurem sempre ler com atenção as questões. Se o examinador quer a incorreta, isso significa dizer que as demais alternativas têm conteúdo correto! De fato, a única alternativa que está em desacordo com a doutrina apresentada é a “c”, já que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4.º).
3. “c”. De acordo com o art. 24, IV.
4. “a”. De acordo com o art. 24, I, XI e XV.
5. “a”. De acordo com o art. 22, IV e XI.
6. “b”. De acordo com o art. 22, XI.
7. “b”. De acordo com o art. 22, XXIX.
8. “d”. De fato, o art. 22, XXVI, da CF estabelece ser competência privativa da União legislar sobre “atividades nucleares de qualquer natureza”. No entanto, trata-se de competência privativa e não exclusiva, como a do art. 21, marcada pela nota da delegabilidade (para outra pessoa de direito público interno). É o que disciplina o parágrafo único do art. 22: lei complementar poderá autorizar os Estados (e acrescente-se o DF, no exercício da competência estadual) a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no art. 22.
9. “c”. Cf. art. 30, I e V.

7. “b”. De acordo com o art. 22, XXIX.
8. “d”. De fato, o art. 22, XXVI, da CF estabelece ser competência privativa da União legislar sobre “atividades nucleares de qualquer natureza”. No entanto, trata-se de competência privativa e não exclusiva, como a do art. 21, marcada pela nota da delegabilidade (para outra pessoa de direito público interno). É o que disciplina o parágrafo único do art. 22: lei complementar poderá autorizar os Estados (e acrescente-se o DF, no exercício da competência estadual) a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no art. 22.
9. “c”. Cf. art. 30, I e V.
10. “d”. Art. 22, XI, da CF/88.
11. “b”.
12. “a”.
13. “c”. Art. 24, VII e XV, da CF/88.
14. “errado”. Na verdade, em relação à competência concorrente (na questão, art. 24, XIII), a superveniência de lei federal suspende a eficácia no que for contrário. Não se trata, portanto, de revogação.
15. “d”. Art. 22, XXV, da CF/88. <i>Letra “a”</i> , art. 24, XV (competência concorrente). <i>Letra “b”</i> , art. 24, I (competência concorrente). <i>Letra “c”</i> , art. 24, V (competência concorrente). <i>Letra “e”</i> , art. 24, XIV (competência concorrente).
16. “b”.
17. “e”. Cf. arts. 22, V (serviços postais — União); 22, IV (águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão); 22, XII (jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia); 22, XIV (populações indígenas); e 24, IV (custas dos serviços forenses).
18. “a”.
19. “e”. Conforme se observa, vem sendo frequente a necessidade de conhecimento da “letra” fria da Constituição, notadamente em relação à competência legislativa. Portanto, foque na leitura dos arts. 21, 22, 23, 24 e 30 da CF/88. A <i>letra “a”</i> exigia o conhecimento do art. 22, I, II e III. A

autorização atingirá, também, o DF no exercício de sua competência de natureza estadual.

23. “certo”. Interessante ter o MPF assumido a linha de maior proteção que vem sendo observada em relação ao amianto e ao fumo, no julgamento de cautelar (cf. *item 7.11*). Como dissemos na parte teórica, essa parece ser a tendência do julgamento de mérito (*pendente*).

24. “a”. *Item I*: art. 22, XIII e parágrafo único. *Item II*: art. 21, VI. Interessante o conhecimento do art. 22, XXI. *Item III*: art. 24, IX e § 1.º. Em relação ao art. 24, IX, lembramos que a EC n. 85/2015 acrescentou ao referido artigo, também como competência concorrente, a legislação sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.

SEPARAÇÃO DE “PODERES” — TEORIA GERAL

■ 8.1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

■ 8.1.1. Aristóteles: identificação das funções do Estado

As primeiras bases teóricas para a “tripartição de Poderes” foram lançadas na Antiguidade grega por **Aristóteles**, em sua obra *Política*, em que o pensador vislumbrava a existência de **três funções distintas** exercidas pelo poder **soberano**, quais sejam, a função de editar normas gerais a serem observadas por todos, a de aplicar as referidas normas ao caso concreto (administrando) e a função de julgamento, dirimindo os conflitos oriundos da execução das normas gerais nos casos concretos.

Acontece que **Aristóteles**, em decorrência do momento histórico de sua teorização, descrevia a **concentração** do exercício de tais funções na figura de uma única pessoa, o soberano, que detinha um poder “incontrastável de mando”, uma vez que era ele quem editava o ato geral, aplicava-o ao caso concreto e, unilateralmente, também resolvia os litígios eventualmente decorrentes da aplicação da lei. A célebre frase de *Luís XIV* reflete tal descrição: “*L’État c’est moi*”, ou seja, “o Estado sou eu”, o soberano.

Dessa forma, **Aristóteles** contribuiu no sentido de **identificar o exercício de três funções estatais distintas**, apesar de exercidas por um único órgão.

■ 8.1.2. Montesquieu: correspondência entre a divisão funcional e a divisão orgânica

Muito tempo depois, a teoria de Aristóteles seria “aprimorada” pela visão precursora do Estado liberal burguês desenvolvida por **Montesquieu** em seu *O espírito das leis*.

O grande avanço trazido por Montesquieu não foi a identificação do exercício de três funções estatais. De fato, partindo desse pressuposto aristotélico, o grande pensador francês inovou dizendo que tais funções estariam intimamente conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Cada função corresponderia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos únicas do soberano. Essa teoria surge em contraposição ao absolutismo, servindo de base estrutural para o desenvolvimento de diversos movimentos, como as revoluções americana e francesa, caracterizando-se, na *Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão*,¹ em seu art. 16,² como verdadeiro **dogma constitucional**.

De acordo com essa teoria, cada Poder exercia uma função típica, inerente à sua natureza, atuando independente e autonomamente, não mais sendo permitido a um único órgão legislar, aplicar a lei e julgar, de modo unilateral, como se percebia no absolutismo.

Cabe alertar, conforme destacou, com acerto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que “a divisão funcional do poder — ou, como tradicionalmente se diz, a ‘separação de poderes’ — que ainda hoje é a base da organização do governo nas democracias ocidentais, não foi invenção genial de um homem inspirado, mas sim é o resultado empírico da evolução constitucional inglesa, qual a consagrou o *Bill of Rights* de 1689. De fato, a ‘gloriosa revolução’ pôs no mesmo pé a autoridade real e a autoridade do parlamento, forçando um compromisso que foi a divisão do poder, reservando-se ao monarca certas funções, ao parlamento outras e reconhecendo-se a independência dos juízes. Esse compromisso foi **teorizado** por **Locke**, no *Segundo tratado do governo*

civil, que o justificou a partir da hipótese do estado de natureza. Ganhou ele, porém, **repercussão estrondosa** com a obra de **Montesquieu**, *O espírito das leis*, que o transformou numa das mais célebres doutrinas políticas de todos os tempos”.³

■ 8.1.3. E qual seria a finalidade da separação dos poderes?

Dimitri, com precisão, observa que “seu objetivo fundamental é preservar a liberdade individual, combatendo a concentração de poder, isto é, a tendência ‘absolutista’ de exercício do poder político pela mesma pessoa ou grupo de pessoas. A distribuição do poder entre órgãos estatais dotados de independência é tida pelos partidários do liberalismo político como garantia de equilíbrio político que evita ou, pelo menos, minimiza os riscos de abuso de poder. O Estado que estabelece a separação dos poderes evita o despotismo e assume feições liberais. Do ponto de vista teórico, isso significa que na base da separação dos poderes encontra-se a tese da existência de nexos causal entre a divisão do poder e a liberdade individual. A separação dos poderes persegue esse objetivo de duas maneiras. Primeiro, impondo a **colaboração** e o **consenso** de várias autoridades estatais na tomada de decisões. Segundo, estabelecendo **mecanismos de fiscalização e responsabilização recíproca dos poderes estatais**, conforme o desenho institucional dos **freios e contrapesos**”.⁴

Nesse sentido, a jurisprudência do STF:

“EMENTA: (...). A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de **conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado**, representa o **princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição**. Esse princípio, que tem assento no art. 2.º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.

(...).

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a **impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado**, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional” (**MS 23.452**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.09.1999, Plenário, *DJ* de 12.05.2000 — original sem grifos).

“EMENTA: Separação e independência dos Poderes: freios e contrapesos: parâmetros federais impostos ao Estado-Membro. Os mecanismos de controle recíproco entre os Poderes, os ‘freios e contrapesos’ admissíveis na estruturação das unidades federadas, sobre constituírem matéria constitucional local, só se legitimam na medida em que **guardem estreita similaridade com os previstos na Constituição da República**: precedentes (...)” (ADI 1.905-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.11.1998, *DJ* de 05.11.2004).

Dentre os vários exemplos desse mecanismo de **freios e contrapesos**, em razão da **interpenetração dos “poderes”** (**interferências** ou **controles recíprocos**), com o objetivo de **evitar abusos de poder**, podemos destacar:

- **art. 5.º, XXXV**: o Poder **Judiciário** pode rever atos de determinada CPI (**Legislativo**) que extrapolem o *postulado da reserva constitucional de jurisdição*, quando, por exemplo, o seu presidente expede um mandado de busca e apreensão em total violação ao art. 5.º, XI;
- **art. 52, I**: compete privativamente ao Senado Federal (**Legislativo**) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República (**Executivo**) nos crimes de responsabilidade;
- **art. 53, § 1.º, c/c o art. 102, I, “b”**: eventual condenação pelo STF (**Judiciário**) de parlamentar federal corrupto (**Legislativo**) que se vale de seu cargo para indevidamente enriquecer (cf. julgamento do denominado “mensalão” na AP 470);
- **art. 62**: as medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República (**Executivo**) poderão ser rejeitadas pelo Congresso Nacional (**Legislativo**);
- **art. 66, § 1.º**: o Chefe do Poder **Executivo** pode sancionar ou vetar

projetos de lei aprovados pelo Parlamento (**Legislativo**);

■ **art. 66, §§ 4.º a 6.º**: o Parlamento (**Legislativo**) poderá “derrubar” o veto lançado pelo Chefe do Poder **Executivo**;

■ **art. 66, § 7.º**: se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República (**Executivo**), nos casos dos §§ 3.º e 5.º, o Presidente do Senado (**Legislativo**) a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado (**Legislativo**) fazê-lo;

■ **art. 63, I e II**: cabe emenda parlamentar (**Legislativo**) em projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República (**Executivo**);

■ **art. 64, § 1.º**: o Presidente da República (**Executivo**) poderá solicitar urgência para o Parlamento (**Legislativo**) apreciar os projetos de sua iniciativa;

■ **art. 97**: os juízes (**Judiciário**) poderão declarar a inconstitucionalidade de lei (**Legislativo**) ou ato normativo do Poder Público (inclusive, como exemplo, de decretos autônomos elaborados pelo **Executivo**);

■ **art. 101, parágrafo único (c/c o art. 52, III, “a”, e o art. 84, XIV)**: os Ministros do STF (**Judiciário**) serão nomeados pelo Presidente da República (**Executivo**), depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (**Legislativo**).

■ **art. 102, I, “a”**: compete ao STF (**Judiciário**) declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual (**Legislativo**).

■ 8.2. FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS

A teoria da “tripartição [5](#) de Poderes”, exposta por Montesquieu, foi adotada por grande parte dos Estados modernos, [6](#) só que de maneira **abrandada**. Isso porque, diante das realidades sociais e históricas, passou-se a permitir uma maior interpenetração entre os Poderes, atenuando a teoria que pregava a separação pura e absoluta deles. [7](#)

Dessa forma, além do exercício de **funções típicas** (*predominantes*),

inerentes e ínsitas à sua natureza, cada órgão exerce, também, outras duas funções atípicas (de natureza típica dos outros dois órgãos). Assim, o legislativo, por exemplo, além de exercer uma função típica, inerente à sua natureza, exerce, também, uma **função atípica** de natureza *executiva* e outra **função atípica** de natureza *jurisdicional*.

Importante esclarecer que, mesmo no exercício da função atípica, o órgão exercerá uma função sua, não havendo aí ferimento ao princípio da separação de Poderes, porque tal competência foi constitucionalmente assegurada pelo poder constituinte originário. Vejamos o quadro abaixo, trazendo uma visão panorâmica das **funções típicas** de cada órgão, bem como **exemplos** de algumas **funções atípicas**:

ÓRGÃO	FUNÇÃO TÍPICA	FUNÇÃO ATÍPICA
LEGISLATIVO	■ legislar ■ fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo	■ Natureza executiva: ao dispor sobre sua organização, provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores etc. ■ Natureza jurisdicional: o Senado julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, I)
EXECUTIVO	■ prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração	■ Natureza legislativa: o Presidente da República, por exemplo, adota medida provisória, com força de lei (art. 62) ■ Natureza jurisdicional: o

		Executivo julga, apreciando defesas e recursos administrativos
JUDICIÁRIO	■ julgar (<i>função jurisdicional</i>), dizendo o direito no caso concreto e dirimindo os conflitos que lhe são levados, quando da aplicação da lei	■ Natureza legislativa: regimento interno de seus tribunais (art. 96, I, “a”) ■ Natureza executiva: administra, v.g., ao conceder licenças e férias aos magistrados e serventuários (art. 96, I, “f”)

Finalmente, pedimos vênia para ressaltar a caracterização feita por José Afonso da Silva⁸ em relação às três funções (típicas) exercidas pelos Órgãos:

■ **função legislativa:** “consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas *leis*”;

■ **função executiva:** “resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se limita à simples *execução das leis*, como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que a função executiva se distingue em *função de governo*, com atribuições políticas, colegislativas e de decisão, e *função administrativa*, com suas três missões básicas: *intervenção, fomento e serviço público*”;

■ **função jurisdicional:** “tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse”.

■ 8.3. IMPROPRIEDADE DA EXPRESSÃO “TRIPARTIÇÃO DE PODERES”

Depois de todo o visto, devemos apenas sistematizar a imprecisão do uso da expressão “tripartição de Poderes”.

Isso porque o poder é **uno, indivisível e indelegável**. O poder não se triparte. O poder é um só, manifestando-se por meio de **órgãos** que exercem **funções**. Dessa maneira, temos:

a) poder: uno, indivisível e indelegável, um atributo do Estado que emana do povo;

b) função: “a função constitui, pois, um modo particular e caracterizado de o Estado manifestar a sua vontade”;[9](#)

c) órgão: “os órgãos são, em consequência, os instrumentos de que se vale o Estado para exercitar suas funções, descritas na Constituição, cuja eficácia é assegurada pelo Poder que a embasa”.[10](#)

Assim, todos os atos praticados pelo Estado decorrem de um só Poder, uno, indivisível e indelegável. Esses atos adquirem diversas formas, dependendo das funções exercidas pelos diferentes órgãos. O órgão legislativo, por exemplo, exerce uma função típica, inerente à sua natureza, além de funções atípicas, conforme vimos no quadro anterior, ocorrendo o mesmo com os órgãos executivo e jurisdicional.

A correspondência entre **funções** e **órgãos** é imposta e decorrente da separação orgânica dos poderes e, naturalmente, está explícita no texto de 1988, destacando-se:

■ **art. 44:** o “Poder” **Legislativo** (*função*) é exercido pelo **Congresso Nacional** (*órgão*), que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

■ **art. 76:** o “Poder” **Executivo** (*função*) é exercido pelo **Presidente da República** (*órgão*), auxiliado pelos Ministros de Estado;

■ **art. 92:** são órgãos do “Poder” **Judiciário** (*função*):[11](#) I — o Supremo Tribunal Federal; I-A — o Conselho Nacional de Justiça; II — o Superior Tribunal de Justiça; III — os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; IV — os Tribunais e Juízes do Trabalho; V — os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI — os Tribunais e Juízes Militares; VII — os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios (*órgãos*).

Feitas essas observações, devemos lembrar que a expressão “tripartição de Poderes”, normalmente, é utilizada sem muito rigor técnico, inclusive pela própria Constituição, que em seu art. 2.º assevera: “São **Poderes** da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Portanto, por “Poderes” entendam-se órgãos, em decorrência do que expusemos acima.

■ 8.4. A INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E A INDELEGABILIDADE DE ATRIBUIÇÕES

Ressaltamos serem os “Poderes” (órgãos) independentes entre si, cada qual atuando dentro de sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida quando da manifestação do *poder constituinte originário*.

Nesse sentido, as atribuições asseguradas não poderão ser delegadas de um Poder (órgão) a outro. Trata-se do **princípio da indelegabilidade de atribuições**. Um órgão só poderá exercer atribuições de outro, ou da natureza típica de outro, quando houver expressa previsão (e aí surgem as funções atípicas) e, diretamente, quando houver delegação por parte do poder constituinte originário, como ocorre, por exemplo, com as leis delegadas do art. 68, cuja atribuição é delegada pelo Legislativo ao Executivo.

Pelo que se observa no quadro abaixo, as Constituições de 1891, 1934, 1946, 1967 e a EC n. 1/69 não só foram explícitas ao proclamar a cláusula da **indelegabilidade**, como também deixaram clara a possibilidade de **interpenetração** entre os poderes a ser materializada naquilo que se denominou **freios e contrapesos**. Vejamos:

CONSTITUIÇÕES	PARTIÇÃO DE FUNÇÕES (quadripartição e a regra da tripartição)	INDEPENDÊNCIA ORGÂNICA
	■ Art. 10. Os Poderes	

1824	Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicial. ■ Art. 9.º A divisão e harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece.	■ <i>Não há ressalva explícita.</i>
1891	■ Art. 15. São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si.	■ Art. 79. O cidadão investido em funções de qualquer dos três Poderes federais não poderá exercer as de outro.
1934	■ Art. 3.º, caput — São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si.	■ Art. 3.º, § 1.º — É vedado aos Poderes constitucionais delegar suas atribuições. ■ Art. 3.º, § 2.º — O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
1937	■ <i>Não existe um dispositivo explícito, muito embora o texto tenha criado capítulos próprios para o Legislativo e</i>	■ <i>Não há ressalva explícita.</i>

	<i>o Judiciário.</i>	
1946	■ Art. 36. São Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.	■ Art. 36, § 1.º — O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. ■ Art. 36, § 2.º — É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
1967	■ Art. 6.º, caput — São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.	■ Art. 6.º, parágrafo único — Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
EC n. 1/69	■ Art. 6.º, caput — São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.	■ Art. 6.º, parágrafo único — Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
1988	■ Art. 2.º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.	■ <i>Não há ressalva explícita.</i>

Embora a regra da **indelegabilidade** e a enunciação da existência de **ressalvas** não estejam individual e expressamente estabelecidas na redação da Constituição de 1988 (em um artigo específico, como se observou nos referidos textos anteriores), não há dúvida de que devam ser reconhecidas no ordenamento atual, seja por se tratar da essência da separação de poderes adotada nos Estados modernos (do contrário, a *separação de poderes* perderia a sua utilidade), seja porque essas exceções (**interferências** ou **controles recíprocos**, em verdadeira **interpenetração de poderes**, materializando os **freios e contrapesos**) podem ser expressamente **identificadas**, o que se viu acima, **ao longo da Constituição**.

Por fim, lembre-se de que a CF/88 erigiu à categoria de **cláusula pétrea a separação de Poderes** (art. 60, § 4.º, III).

■ 8.5. QUESTÕES

1. (Magistratura/SP/170.º) Como decorrência do princípio da independência e harmonia dos Poderes: I) o Poder Executivo não participa do processo legislativo; II) ao Poder Judiciário é vedada a prática de atos administrativos; III) cada um dos Poderes pode organizar livremente seus serviços, observando apenas os preceitos constitucionais e legais. Pode-se dizer que:

- a) apenas a afirmativa I é correta;
- b) apenas a afirmativa II é correta;
- c) apenas a afirmativa III é correta;
- d) há mais de uma afirmativa correta.

2. (OAB/SP/101.º) A divisão dos Poderes, bem como sua independência, não é absoluta. Há interferências que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos à busca do equilíbrio necessário. Só não é exemplo de freios e contrapesos:

- a) o Executivo tem participação importante no Legislativo quer pela iniciativa das leis, quer pela sanção e pelo veto;
- b) o Congresso, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá rejeitar o veto do Executivo;

- c) os Tribunais, embora não interfiram no Legislativo, estão autorizados a declarar a inconstitucionalidade das leis;
- d) o Poder Legislativo se organiza em duas Casas, Câmara e Senado, sistema denominado bicameralismo.

3. (TJ/PI — CESPE/UnB) Quanto às teorias das formas de governo e da soberania, assinale a opção correta:

- a) Para Maquiavel, as formas de governo são os principados, as repúblicas e as democracias.
- b) Jean Bodin passou para a história do pensamento político como o teórico da soberania. Como para ele soberania significa poder supremo, o soberano não estaria submetido a qualquer regra, salvo as leis naturais, as divinas e o direito privado.
- c) Para Hobbes, o poder soberano deve ser dividido, pois a melhor forma de governo seria a do governo misto.
- d) Para Montesquieu, três são as formas de governo: monarquia, aristocracia e política ou timocracia, que se degeneram por meio da tirania, da oligarquia e da democracia, respectivamente.
- e) Para Aristóteles, os governos são republicano — no qual todo o povo, ou pelo menos uma parte dele, detém o poder supremo —; monárquico — em que uma só pessoa governa —; e despótico — em que um só arrasta tudo e todos com sua vontade e seus caprichos, sem leis ou freios.

4. (DP/SP/2006 — FCC) Sobre o princípio da separação de poderes, ao prescrever a independência e harmonia entre as diversas funções do Estado (legislativa, executiva e judiciária), bem como um sistema de controles recíprocos, é possível afirmar que:

- I. A teoria dos *checks and balances* prevê que a cada função foi dado o poder para exercer um grau de controle direto sobre as outras, mediante a autorização para o exercício de uma parte, embora limitada, das outras funções.
- II. Entre 1989 e 1998, 14% das leis aprovadas foram de autoria de deputados e senadores ou de comissões parlamentares, o que demonstra a preponderância do poder executivo na função legislativa no Brasil.
- III. A cláusula da separação de poderes prevista no inciso III do parágrafo 4.º do artigo 60 torna inconstitucional emendas que modifiquem o arranjo de separação de poderes existente no texto constitucional.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

5. (Agente Técnico Legislativo de SP — Direito — FCC/2010) No Brasil, as funções atípicas, relacionadas à teoria da separação de poderes:

- a) são consideradas inconstitucionais, pois ferem a harmonia e a independência dos Poderes.
- b) só poderão ser realizadas mediante expressa previsão legal.
- c) possibilitam ao Senado Federal julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade.
- d) permitem aos Tribunais Superiores aprovar súmula com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.
- e) garantem ao Poder Executivo prerrogativa para apurar fato determinado e por prazo certo com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

6. (Procurador de Estado — PGE-AL/CESPE/UnB/2009) Tendo como referência inicial o texto, assinale a opção correta:

Quando, na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o Poder Legislativo se junta ao Executivo, desaparece a liberdade; pode-se temer que o monarca ou o senado promulguem leis tirânicas, para aplicá-las tiranicamente. Não há liberdade se o Poder Judiciário não está separado do Legislativo e do Executivo. Se houvesse tal união com o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, já que o juiz seria ao mesmo tempo legislador. Se o Judiciário se unisse com o Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa, ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis, ou de populares, exercesse os três Poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e conflitos dos cidadãos. Montesquieu. In: Norberto Bobbio. *A teoria das formas de governo*. 10. ed. Brasília: EDUnB, p. 137 (com adaptações).

- a) Para a moderna doutrina constitucional, cada um dos poderes constituídos exerce uma função típica e exclusiva, afastando o exercício por um poder de função típica de outro.

- b) A CF, atenta às discussões doutrinárias contemporâneas, não consigna que a divisão de atribuições estatais se faz em três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.
- c) O poder soberano é uno e indivisível e emana do povo. A separação dos poderes determina apenas a divisão de tarefas estatais, de atividades entre distintos órgãos autônomos. Essa divisão, contudo, não é estanque, pois há órgãos de determinado poder que executam atividades típicas de outro. Um exemplo disso, na CF, é a possibilidade de as comissões parlamentares de inquérito obterem acesso a decisão judicial protegida sob o manto do segredo de justiça.
- d) A edição de súmula vinculante vedando a nomeação de parentes da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança em qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios viola o princípio da separação dos poderes.
- e) A cada um dos poderes foi conferida uma parcela da autoridade soberana do Estado. Para a convivência harmônica entre esses poderes existe o mecanismo de controles recíprocos (*checks and balances*). Esse mecanismo, contudo, não chega ao ponto de autorizar a instauração de processo administrativo disciplinar por órgão representante de um poder para apurar a responsabilidade de ato praticado por agente público de outro poder.

7. (Analista Judiciário — TRT/17 — Área Administrativa — CESPE/UnB/2009) A separação dos Poderes no Brasil adota o sistema norte-americano *checks and balances*, segundo o qual a separação das funções estatais é rígida, não se admitindo interferências ou controles recíprocos.

8. (TJ-RR — Administrador — CESPE/UnB/2012) Acerca dos elementos do Estado e da abrangência de seus Poderes, julgue o item a seguir.

O sistema *checks and balances*, criado por ingleses e norte-americanos, consiste no método de freios e contrapesos adotado no Brasil. Nesse sistema, todos os poderes do Estado desempenham funções e praticam atos que, a rigor, seriam de outro poder, de modo que um poder limita o outro.

9. (Técnico Judiciário — Área Administrativa — TRT/3.^a Região — FCC/2009) Na hipótese de o TRT da 3.^a Região elaborar ou alterar o respectivo Regimento Interno, estará desempenhando uma função:

- a) atípica administrativa.
- b) típica jurisdicional.
- c) atípica legislativa.
- d) típica judicialiforme.
- e) atípica autoexecutiva.

10. (STF — Analista Judiciário — Contabilidade — CESPE/2008) A respeito do direito constitucional, julgue o item que se segue:

Um tribunal, ao elaborar seu regimento interno, exerce uma função atípica legislativa.

11. (Procurador — TCE-SP — FCC/2011) Considera-se função atípica do Poder Executivo, sob a ótica do princípio da separação de poderes, a previsão constitucional segundo a qual compete ao Presidente da República

- a) vetar e sancionar projetos de lei.
- b) suspender a eficácia de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
- c) editar decretos e regulamentos para a execução de leis.
- d) nomear Ministros do Supremo Tribunal Federal, após arguição pelo Congresso Nacional.
- e) editar leis delegadas e medidas provisórias.

12. (Perito Criminal — Específicos — CESPE/UnB/2011) Acerca dos princípios constitucionais, julgue o item seguinte:

Não viola o princípio constitucional da separação dos poderes a apreciação, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo.

13. (Técnico Judiciário — Segurança — TRT6 — FCC/2012) No que concerne à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na Constituição Federal, que:

- a) o Judiciário é hierarquicamente superior ao Executivo e ao Legislativo, na medida em que àquele incumbe decisão final sobre a constitucionalidade das normas vigentes.
- b) são independentes e harmônicos entre si, impondo-se influências e limitações recíprocas que se prestam à limitação do poder estatal.
- c) o Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo, na medida em que lhe é autorizado legislar por meio de medidas provisórias.
- d) o Legislativo é hierarquicamente superior ao Executivo, na medida em que pode derrubar o veto do Chefe do Executivo a determinada lei, tornando-a vigente.

e) são independentes e harmônicos, não se relacionando entre si, devendo eventual conflito ser dirimido por organismo supranacional.

14. (Analista MPU — CESPE/UnB/2013) No que se refere à CF, às emendas constitucionais e aos princípios fundamentais, julgue o item a seguir:

A CF instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis.

15. (Analista Legislativo/CD — Consultor Legislativo — Área III, CESPE/UnB/2014) À luz dos princípios fundamentais de direito constitucional positivo brasileiro, julgue o item a seguir:

Se, em certa ação judicial, o juízo competente impuser ao Poder Executivo determinada obrigação, sob pena de multa diária pelo seu descumprimento, tal imposição não ofenderá o princípio da separação dos poderes.

16. (Administrador — CONSULPLAN/MAPA/2014) Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, não existe supremacia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo cada um dotado de uma função típica, sem excluir, contudo, em certas ocasiões, o exercício, por cada um deles, de atribuições próprias dos outros. Com relação aos poderes do Estado e suas funções, é INCORRETO afirmar que o Poder

- a) Judiciário tem como função típica a jurisdicional, que consiste no provimento de decisões, com base na lei.
- b) Executivo tem como funções precípua a de fiscalizar e controlar a legalidade dos atos emanados pelo Poder Legislativo.
- c) Legislativo possui a atribuição de funções administrativas, como, por exemplo, quando dispõe sobre sua organização interna.
- d) Legislativo, de forma típica, tem a função de legislar e fiscalizar, exercendo também os controles político-administrativo e financeiro-orçamentário.

■ GABARITO ■

1. “c”. A “l” é errada, pois, como veremos ao tratar do processo legislativo, o Chefe do Executivo
--

participa por meio de sanção ou veto. A “II” é errada, porque, como vimos, o Judiciário exerce função atípica de natureza administrativa, por exemplo, ao conceder férias aos seus funcionários.
2. “d”.
3. “b”.
4. “c”.
5. “c”. A letra “a” está errada, na medida em que as funções atípicas são introduzidas pelo poder constituinte originário e, assim, perfeitamente possível a instituição de exceções à regra geral. Portanto, a letra “b” também se mostra incorreta, já que a exceção deverá estar prevista na Constituição, e não em lei. A letra “d”, por sua vez, está errada, porque a <i>Reforma do Judiciário</i> (EC n. 45/2004) estabeleceu que apenas o STF poderá editar súmula vinculante. Finalmente, a letra “e” está errada, na medida em que a previsão indicada foi constitucionalmente assegurada para a CPI (Legislativo), e não para o Executivo (art. 58, § 3.º).
6. “e”.
7. “errado”.
8. “certo”.
9. “c”.
10. “certo”.
11. “e”.
12. “certo”.
13. “b”.
14. “certo”.
15. “certo”.
16. “b”.

PODER LEGISLATIVO

■ 9.1. ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

■ 9.1.1. Estrutura do Poder Legislativo federal

A análise do Poder legislativo (ou, de modo mais técnico, órgão legislativo) deve ser empreendida levando em conta a forma de estado introduzida no Brasil, verificando-se de que modo ocorre a sua manifestação em âmbito federal, estadual, distrital e municipal.

Assim, diz-se que no Brasil vigora o **bicameralismo federativo**, no âmbito federal. Ou seja, o Poder Legislativo no Brasil, em âmbito federal, é **bicameral**, isto é, composto por duas Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a primeira constituída por representantes do **povo** e a segunda, por representantes dos **Estados-Membros** e do **Distrito Federal**, adjetivando, assim, o nosso bicameralismo, que é do tipo federativo, como visto.

Pelo exposto, outra não poderia ser a redação do art. 44 da CF/88, que diz: “o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”.

As regras fundamentais sobre o legislativo federal serão estudadas individualmente, destacando-se a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as reuniões dos parlamentares, as comissões e demais regras atinentes aos Deputados e Senadores, como imunidades, incompatibilidades e impedimentos,

perda do mandato etc. Neste momento, teceremos alguns comentários a respeito do legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais, para, em um segundo momento, voltarmos ao legislativo federal.

■ 9.1.2. Estrutura do Poder Legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais

O Poder Legislativo em âmbito estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais (estes últimos, quando criados), ao contrário da estrutura do legislativo federal, é do tipo **unicameral**, pois composto por uma única Casa, conforme se observa pela leitura dos arts. 27, 29, 32 e 33, § 3.º, última parte, todos da CF/88.

■ 9.1.2.1. Estrutura do Poder Legislativo estadual

■ **unicameralismo**: o legislativo estadual é exercido pela **Assembleia Legislativa**, composta pelos **Deputados Estaduais**, também representantes do **povo** do Estado;

■ **número de deputados estaduais**: “o número de Deputados à **Assembleia Legislativa** corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze” (art. 27, *caput*).

Portanto, até o número de 12 Deputados Federais, o número de Deputados Estaduais será obtido pela multiplicação por 3 (o triplo). Acima de 12, segue a seguinte fórmula: $y = (x - 12) + 36$ em que **y** corresponde ao número de Deputados Estaduais e **x**, ao número de Deputados Federais. A fórmula, para facilitar, pode ser assim resumida: $y = x + 24$, em que **y** corresponde ao número de Deputados Estaduais e **x**, ao número de Deputados Federais (quando forem acima de 12). Veja a tabela abaixo e “viva a matemática”!:

--	--	--

NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS (x)	NÚMERO DE DEPUTADOS ESTADUAIS (y)	FÓRMULA
8	24 ¹	o triplo
9	27	o triplo
10	30	o triplo
11	33	o triplo
12	36	o triplo
13	37	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
14	38	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
(...)		
68 ²	92	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
69	93	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
70	94 ³	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$

■ **mandato:** o mandato dos Deputados Estaduais será de **4 anos**;

■ **outras regras:** as regras da CF sobre **sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas** serão aplicadas aos parlamentares estaduais (art. 27, § 1.º). Desta feita, o regime

reservado aos parlamentares federais será o mesmo a ser observado pelos estaduais;

■ **remuneração:** determina o § 2.º do art. 27 que o **subsídio** dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, não podendo ser superior a **75%** daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4.º, 57, § 7.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I. Trata-se de subteto do funcionalismo a ser respeitado no âmbito do Poder Legislativo Estadual, segundo a regra trazida pela **Reforma da Previdência** (art. 37, XI — EC n. 41/2003). Entendemos que o subteto do funcionalismo a ser observado no âmbito do Poder Legislativo Estadual continua sendo o subsídio do Deputado Estadual, apesar da novidade trazida no art. 37, § 12, pela **EC n. 47/2005**. Isso porque a parte final é bem clara ao dizer que a flexibilização da “PEC Paralela” não se aplica ao subsídio do Deputado Estadual, que continua sendo o parâmetro e limite, nos termos do art. 37, XI, que não foi modificado.

■ **9.1.2.2. Estrutura do poder legislativo municipal**

■ **unicameralismo:** o legislativo municipal é exercido pela **Câmara Municipal (Câmara dos Vereadores)**, composta pelos **Vereadores**, representantes do **povo** do Município;

■ **número de Vereadores:** o número de Vereadores será proporcional à população do Município, até os limites estabelecidos no art. 29, IV, nos termos da redação conferida pela **EC n. 58/2009.4**

Cabe lembrar que, antes da EC n. 58/2009, a **Resolução n. 21.702/2004/TSE**, partindo do julgamento do RE 197.917, que definiu a proporcionalidade em relação ao Município de Mira Estrela, produziu efeitos para todo o País.

■ **mandato:** o mandato dos Vereadores será de **4 anos**;

■ **inviolabilidade ou imunidade material:** os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na

circunscrição do Município (art. 29, VIII, estudado mais adiante);

■ **remuneração:** as regras sobre a remuneração dos Vereadores, inicialmente, foram fixadas no art. 29, V, da CF/88, cuja redação foi alterada pela EC n. 19/98. A EC n. 1/92 acrescentou o inciso VI ao referido art. 29, que, por sua vez, também foi alterado pela **reforma administrativa** (EC n. 19/98). Tanto na primeira reforma como na segunda, fixou-se que o **valor da remuneração dos Vereadores** corresponderia a, no máximo, 75% do subsídio, em espécie, dos **Deputados Estaduais**, sendo fixado por lei de **iniciativa da Câmara dos Vereadores**. Felizmente, de maneira mais transparente, outra reforma sofreu o texto constitucional, por meio da **EC n. 25, de 14.02.2000**, que alterou o inciso VI do art. 29 e acrescentou o art. 29-A à Constituição Federal, estipulando critérios mais claros e objetivos para o controle dos gastos públicos, no caso em análise, do Poder Legislativo Municipal.

Agora, com as novas regras, a fixação dos percentuais não ficará mais ao puro arbítrio dos Vereadores, através de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores, na medida em que os **percentuais máximos** já foram estabelecidos pelo próprio poder constituinte derivado reformador, na EC n. 25/2000. De acordo com as novas regras (art. 29, VI, da CF/88), o **limite máximo** dos subsídios dos Vereadores continua a ser **75%** do subsídio dos Deputados Estaduais,⁵ porém variável de acordo com o número de habitantes de cada Município, segundo a tabela abaixo, não podendo o **total da despesa** com a **remuneração dos Vereadores** ultrapassar o montante de **5%** da receita do Município (art. 29, VII):

TAMANHO DO MUNICÍPIO — NÚMERO DE HABITANTES (y)	SUBSÍDIO MÁXIMO DO VEREADOR — (x)% DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS
y < 10.000	20%
10.001 < y < 50.000	30%

50.001 < y < 100.000	40%
100.001 < y < 300.000	50%
300.001 < y < 500.000	60%
500.001 < y	75%

Dessa forma, de acordo com as novas regras, o subsídio dos Vereadores será **fixado** pelas respectivas **Câmaras Municipais**, em cada legislatura para a **subsequente**, ou seja, fica vedada tal prática na legislatura vigente. Na verdade, a fixação dos subsídios continuará a ocorrer na legislatura (período de 4 anos = ao mandato) imediatamente anterior à subsequente, porém até os limites máximos já previamente determinados pela EC n. 25/2000, de acordo com o número de habitantes do Município.

Isso porque, conforme já decidiu o STF, a fixação de subsídios na mesma legislatura caracteriza “ato lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à **moralidade administrativa**, patrimônio moral da sociedade” (STF, RE 172.212-6/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2.^a Turma, *DJ* 1, de 27.03.1998, p. 19). Ressalte-se que na fixação dos subsídios deverão ser observadas as regras da CF/88, da CE, bem como os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica.

Cabe lembrar, ainda, o subteto determinado pela **Reforma da Previdência** (art. 37, XI, da EC n. 41/2003), qual seja, no Município, nenhum subsídio poderá ser superior àquele do **Prefeito**.

Pois bem, além das regras já mencionadas, a **EC n. 25/2000** trouxe outros limites, estes, todavia, com caráter genérico e que foram reescalados pela **EC n. 58/2009**. De acordo com o art. 29-A, o **total da despesa** do Poder Legislativo Municipal, **incluídos** os subsídios dos Vereadores e **excluídos** os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais indicados na tabela a seguir, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5.º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício

anterior:

TAMANHO DO MUNICÍPIO — NÚMERO DE HABITANTES (y)	O TOTAL DA DESPESA (INCLUÍDOS OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E EXCLUÍDOS OS GASTOS COM INATIVOS) NÃO PODE ULTRAPASSAR OS SEGUINTE PERCENTUAIS (SOBRE O SOMATÓRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS NO § 5.º DO ART. 153 E NOS ARTS. 158 E 159, EFETIVAMENTE REALIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR)
y < 100.000	7%
100.001 < y < 300.000	6%
300.001 < y < 500.000	5%
500.001 < y < 3.000.000	4,5%
3.000.001 < y < 8.000.000	4%
8.000.001 < y	3,5%

Além desses limites, o § 1.º do art. 29-A, também acrescentado, estatui que a Câmara Municipal não gastará mais de **70%** de sua **receita** com a **folha de pagamentos**, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, ou seja, a remuneração de todo o pessoal da Câmara dos Vereadores. O desrespeito a essa regra constitui **crime de responsabilidade** do **Presidente da Câmara Municipal**. Convém lembrar que, dentro dessa filosofia e política de contenção

de gastos do Poder Legislativo Municipal, o art. 29, VII, acrescentado pela EC n. 1/92, já estabelecia que o **total da despesa** com a **remuneração dos Vereadores** (parte da **folha de pagamentos**) não poderia ultrapassar o montante de **5%** da receita do Município.

Já o **Prefeito Municipal**, de acordo com as novas regras, além do **crime de responsabilidade** previsto no Decreto-lei n. 201/67, que será estudado em momento oportuno, praticará **crime de responsabilidade** caso deixe de efetuar o repasse dos valores para o Poder Legislativo, de acordo com as regras do art. 29-A, § 2.º, I, II e III, ou seja: **a)** efetuar repasse que supere os limites definidos no art. 29-A em análise; **b)** não enviar o referido repasse até o dia **20** de cada mês; **c)** enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária.

Por fim, devemos destacar a *vacatio legis* prevista no art. 3.º da EC n. 25/2000, que, embora tenha sido publicada no *DOU* eletrônico de 15.02.2000, só entrou em vigor em **1.º de janeiro de 2001**, abarcando, portanto, essa nova legislatura que se iniciou na mesma data.

■ 9.1.2.3. Estrutura do poder legislativo distrital

■ **unicameralismo:** o legislativo distrital é exercido pela **Câmara Legislativa** (art. 32, *caput*), composta pelos Deputados Distritais, que representam o povo do distrito federal;

■ **aplicação das características dos Estados:** como determina o art. 32, § 3.º, aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27, ou seja, todas as regras estabelecidas para os Estados valem para o distrito federal.

■ 9.1.2.4. Estrutura do poder legislativo dos Territórios Federais

■ **regra geral:** o art. 33, § 3.º, última parte, determina que a lei disporá sobre as eleições para a **Câmara Territorial** e sua competência

deliberativa. Como não existem Territórios Federais (apesar de poderem vir a ser criados), ainda não foi regulamentado esse dispositivo constitucional. Cabe observar que, quando criados, de acordo com o art. 45, § 2.º, cada Território elegerá o número fixo de **4 Deputados Federais**, para compor a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional.

■ 9.2. ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

De acordo com o **art. 48** da CF/88, cabe ao **Congresso Nacional**, com a **sanção do Presidente da República**, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

- sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
- transferência temporária da sede do Governo Federal;
- concessão de anistia;
- organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios, e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal (*EC n. 69/2012*);
- criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, “b”, já que, quando **vagos** os cargos ou funções públicas, caberá ao Presidente, mediante decreto, dispor sobre a extinção;
- criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública

(confira, também, o art. 88 da CF/88, alterado pela EC n. 32/2001);

- telecomunicações e radiodifusão;
- matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal;
- fixação do subsídio dos Ministros do STF, observado o que dispõem os arts. 39, § 4.º; 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I.

Alertamos que, de acordo com o art. 84, VI, “a”, na nova redação dada pela **EC n. 32/2001**, compete privativamente ao **Presidente da República** (cf. parágrafo único do art. 84) dispor, mediante **decreto**, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar o aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos**.

Agora **cuidado**. O **art. 49** trata das matérias de **competência exclusiva** do Congresso Nacional, sendo **dispensada a manifestação do Presidente da República**, através de sanção ou veto (art. 48, *caput*). Como veremos ao comentar as espécies normativas, as atribuições referidas no art. 49 são materializadas por **decreto legislativo**.⁶

Para os concursos públicos, entendemos indispensável o conhecimento das referidas matérias, fazendo-se um contraponto em relação àquelas do art. 48.

Dessa forma, é da **competência exclusiva do Congresso Nacional** (art. 49):

- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
- autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar (cf. LC n. 90/97, com as alterações introduzidas pela LC n. 149/2015);
- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado

de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

- mudar temporariamente sua sede;

- fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;

- fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;

- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

- zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

- apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

- escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

- aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;

- autorizar referendo e convocar plebiscito;

- autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

- aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

■ 9.3. CÂMARA DOS DEPUTADOS

■ 9.3.1. Aspectos fundamentais

■ **composição:** a Câmara dos Deputados é composta por **representantes do povo**,⁷ ou seja, por Deputados Federais eleitos que manifestam a vontade popular. Lembramos que todo o poder emana do povo, que o exerce, ou de forma direta (ex.: plebiscito, referendo e iniciativa popular — soberania popular, art. 14, I-III), ou por meio de seus representantes, que em âmbito federal são os Deputados Federais (cabe repetir que, nas outras esferas, o Poder Legislativo é **unicameral**, sendo eleitos, também, pelo povo, para representá-los, os Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores, respectivamente para o legislativo estadual, do distrito federal e municipal). Por fim, destacamos que cada Território Federal, quando criado, elegerá o número **fixo** de **4** Deputados Federais, independentemente da população, não havendo representação no Senado Federal, já que não terão autonomia federativa, sendo simples descentralização da União — autarquia federal;

■ **eleição:** os Deputados Federais são eleitos pelo povo segundo o **princípio proporcional**. Ou seja, “o número total de Deputados, bem como a representação por Estados e pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar, proporcionalmente à **população**,⁸ procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de **oito** ou mais de **setenta** Deputados” (art. 45, § 1.º);

■ **número de Deputados Federais:** como referido, o número de Deputados Federais será proporcional à população de cada Estado e do Distrito Federal, não podendo cada Estado e o DF ter menos que **8**, nem mais que **70** Deputados Federais. Relembrar que os Territórios Federais, se vierem a ser criados, elegerão um número **fixo** de **4** Deputados — art. 45, § 2.º. O número total de Deputados Federais foi fixado pela LC n. 78/93 em **513**;

A Constituição foi explícita ao determinar que a **lei complementar** deverá estabelecer não apenas o **número total de deputados federais** (no caso, como citado, fixado em 513), como, também, a **representação por Estado e pelo DF**. Ocorre que a LC n. 78/93, ao disciplinar o assunto, em seu art. 1.º, parágrafo único, **delegou** a segunda obrigação (fixação da representação por

Estado e pelo DF) ao **TSE**.

O STF entendeu essa delegação como **inconstitucional**. Trata-se de critério envolvendo **juízo de valor** a ser determinado **necessariamente** pelo **Parlamento**, não se admitindo a transferência dessa atribuição para o TSE ou para qualquer outro órgão. Na mesma assentada, por conseguinte, os Ministros declararam a inconstitucionalidade da **Res. n. 23.389/2013 do TSE** que disciplinava o tamanho das bancadas para cada Estado e para o DF.⁹

- **mandato:** o mandato de cada Deputado é de **4 anos**, período esse correspondente à **legislatura** (art. 44, parágrafo único);

- **renovação dos Deputados:** a cada **4 anos** serão renovados os Deputados, permitida a reeleição;

- **remuneração:** de acordo com o **DLG n. 276, de 18.12.2014**, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49 da CF/88, foi fixado em **R\$ 33.763,00**, a partir de **1.º.02.2015**, igualando-se ao subsídio mensal dos Ministros do STF (cf. *item 9.6* e novos valores no *item 22.3.2*).

■ 9.3.2. Requisitos para a candidatura dos Deputados Federais

- **brasileiro nato ou naturalizado** (art. 14, § 3.º, I) a exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência daquela Casa, consoante estabelece o art. 12, § 3.º, II;

- **maior de 21 anos** (art. 14, § 3.º, VI, “c”);

- **pleno exercício dos direitos políticos** (art. 14, § 3.º, II);

- **alistamento eleitoral** (art. 14, § 3.º, III);

- **domicílio eleitoral na circunscrição** (art. 14, § 3.º, IV);

- **filiação partidária** (art. 14, § 3.º, V).

■ 9.3.3. Competências privativas da Câmara dos Deputados

As matérias de competência privativa¹⁰ dos Deputados Federais estão previstas no art. 51 da CF/88 e **não** dependerão de sanção presidencial, nos termos do art. 48, *caput*. Tais atribuições, como veremos ao tratar das espécies normativas, são materializadas por meio de **resoluções**.

Nos termos da Constituição, compete privativamente à **Câmara dos Deputados**:

- autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
- proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
- elaborar seu regimento interno;
- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a **iniciativa de lei** para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Em relação ao art. 51, IV, cumpre notar que a Câmara dos Deputados tem competência apenas para a **iniciativa** de projeto de lei que vise à fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços, devendo, necessariamente, depois de aprovada nas duas Casas, a matéria ir à sanção do Presidente da República. Trata-se de **novidade** introduzida pela **EC n. 19/98**, que **retirou** da CD a **competência privativa** para a fixação da referida remuneração.

Devemos alertar que a competência para fixar idêntico **subsídio** para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I, nos termos do **art. 49, VII**, é do **Congresso Nacional**, por **Decreto Legislativo** (cf. *item 9.6*).

- eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

■ 9.4. SENADO FEDERAL

■ 9.4.1. Aspectos fundamentais

■ **composição:** o Senado Federal é composto por representantes dos **Estados** e do **Distrito Federal**. Quando criados, os Territórios Federais não terão representação no Senado Federal, na medida em que não terão autonomia federativa;

■ **eleição:** os senadores são eleitos pelo povo segundo o **princípio majoritário**, ou seja, não mais se trata de estabelecer um número proporcional à população, mas, sim, de eleger ao Senado aquele candidato que obtiver nas urnas o maior número de votos;

■ **número de Senadores:** cada Estado e o Distrito Federal **elegerão o número fixo de 3 Senadores**, sendo que cada Senador será eleito com **2 suplentes**;

■ **mandato:** o mandato de cada Senador é de **8 anos**, portanto, duas **legislaturas**;

■ **renovação dos Senadores:** cada Senador eleito cumpre mandato de 8 anos. Cada Estado e o Distrito Federal elegem um número fixo de 3 Senadores, com 2 suplentes cada um. A renovação, porém, dos Senadores eleitos dar-se-á de quatro em quatro anos, na proporção de **1/3** e **2/3**. Vejamos o exemplo: em 1998 foi eleito um Senador que cumprirá mandato de 1999 a 2006. Em 1999, já existiam 2 Senadores eleitos desde 1994 (início do mandato em 1995), ou seja, já tinham cumprido 4 anos do mandato no final de 1998. Como em 1998 foi trocado 1 dos 3, em 2002 eleger-se-ão 2 dos 3 (para começar um novo mandato de 8 anos em 2003). Assim, sempre existirão 3 Senadores, só que a renovação deles se dará a cada 4 anos, por 1 e 2/3;

■ **remuneração:** de acordo com o **DLG n. 276, de 18.12.2014**, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49 da Constituição Federal, foi fixado em **R\$ 33.763,00**, a partir de **1.º.02.2015**, igualando-se ao subsídio mensal dos Ministros do

STF (cf. *item 9.6* e novos valores no *item 22.3.2*).

■ 9.4.2. Requisitos para a candidatura dos Senadores

■ **brasileiro nato ou naturalizado** (art. 14, § 3.º, I) a exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência daquela Casa, conforme estabelece o art. 12, § 3.º, III;

■ **maior de 35 anos** (art. 14, § 3.º, VI, “a”);

■ **pleno exercício dos direitos políticos** (art. 14, § 3.º, II);

■ **alistamento eleitoral** (art. 14, § 3.º, III);

■ **domicílio eleitoral na circunscrição** (art. 14, § 3.º, IV);

■ **filiação partidária** (art. 14, § 3.º, V).

■ 9.4.3. Competências privativas do Senado Federal

As matérias de competência privativa [11](#) do Senado Federal estão previstas no art. 52 da CF/88 e **não** dependerão de sanção presidencial (art. 48, *caput*) para a sua maturação. Tais atribuições, como veremos ao tratar das espécies normativas, são materializadas através de **resoluções**.

Assim, nos termos da Constituição, compete privativamente ao **Senado Federal**:

■ processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

■ processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; (redação dada pela EC n. 45, de 2004)

■ aprovar previamente, por **voto secreto**, após arguição pública, a escolha de: **a)** Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; **b)** Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; **c)** Governador de Território; **d)** Presidente e diretores do Banco Central; **e)** Procurador-Geral da República; **f)** titulares de outros cargos que a lei determinar;

■ aprovar previamente, por **voto secreto**, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

■ autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

■ fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

■ dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

■ dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

■ estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

■ suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

■ aprovar, por maioria absoluta e por **voto secreto**, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

■ elaborar seu regimento interno;

■ dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Como vimos em relação à Câmara dos Deputados, o Senado Federal, também a partir da **EC n. 19/98**, passou a ter competência **apenas** para a **iniciativa de projeto de lei** para fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços.

Devemos alertar, conforme já visto em relação à Câmara, que a competência para fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I, nos termos do **art. 49, VII**, é do **Congresso Nacional**, por **Decreto Legislativo** (cf. *item 9.6*).

- eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
- avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

■ 9.5. QUADRO COMPARATIVO E DELIBERAÇÕES

	SENADO FEDERAL	CÂMARADOS DEPUTADOS
COMPOSIÇÃO	■ Representantes dos Estados e do Distrito Federal	■ Representantes do povo
SISTEMA DE ELEIÇÃO	■ Princípio majoritário	■ Princípio proporcional à população de cada Estado e do DF, sendo que os TFs elegerão 4 (art. 45, § 2.º)
NÚMERO DE	■ 3 Senadores por Estado e pelo DF, cada qual com 2 suplentes.	■ A LC n. 78/93 fixou em 513 Deputados Federais . Nenhum Estado nem o DF terão menos que

PARLAMENTARES	Atualmente, 81 Senadores (26 Estados x 3 = 78 + 3 do DF)	8 , nem mais que 70 Deputados. Os Territórios, se criados, elegerão 4 Deputados
MANDATO	■ 8 anos = 2 legislaturas	■ 4 anos = 1 legislatura
RENOVAÇÃO	■ A cada 4 anos, por 1/3 e 2/3 , sendo que cada Senador cumpre o mandato de 8 anos	■ A cada 4 anos, sendo que cada Deputado cumpre o mandato de 4 anos
IDADE MÍNIMA (CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE)	■ 35 anos	■ 21 anos

As Casas parlamentares, no exercício de suas atribuições, deliberam por meio de votação, que poderá ser **secreta** ou **ostensiva**, ou seja, pública, por meio do voto “aberto”, prestigiando, neste último caso, a transparência que deve orientar a atuação dos representantes do povo.

O voto secreto é garantia do eleitor. Os parlamentares têm o dever de prestação de contas (**princípio da publicidade**) e, nesse sentido, reforça-se a ideia de votação aberta. Algumas reformas aboliram a votação secreta, mas algumas ainda continuam sem a publicidade esperada. Vejamos:

DISPOSITIVO	COMPETÊNCIA/ ASSUNTO	VOTAÇÃO
	■ Senado Federal: aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de: a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;	

Art. 52, III	b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; c) Governador de Território; d) Presidente e diretores do Banco Central; e) Procurador-Geral da República; f) titulares de outros cargos que a lei determinar.	SECRETA
Art. 52, IV	■ Senado Federal: aprovar previamente, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.	SECRETA
Art. 52, XI	■ Senado Federal: aprovar, por maioria absoluta, a exoneração, de ofício, do PGR antes do término de seu mandato.	SECRETA
Art. 53, § 2.º (EC 35/2001) n.	■ Casa Legislativa (CD ou SF): resolver sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável de membros do Congresso Nacional.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)
Art. 53, § 3.º (EC 35/2001) n.	■ Casa Legislativa (CD ou SF): sustar o andamento de ação penal contra parlamentar.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)
Art. 55, § 2.º (EC 76/2013) n.	■ Casa Legislativa (CD ou SF): nos casos dos incisos I, II e VI, do art. 55, decidir sobre a perda do mandato, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)

Art. 66, § 4.º (EC n. 76/2013)	■ Sessão conjunta da CD e do SF: apreciação sobre o veto presidencial apostado a projeto de lei.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)
-----------------------------------	---	---

■ 9.6. REMUNERAÇÃO DOS PARLAMENTARES

■ 9.6.1. Subsídio mensal

Vimos que, de acordo com o **DLG n. 276, de 18.12.2014**, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49 da CF/88, foi fixado em **R\$ 33.763,00**, a partir de **1.º.02.2015**, igualando-se, assim, ao subsídio de Ministros do STF (teto do funcionalismo), estabelecido pela **Lei n. 13.091, de 12.01.2015**.

A título de curiosidade, indicamos a evolução do valor estabelecido em 2007, depois em 2010 e o atual previsto no referido decreto legislativo de 2014, com expressivo aumento de 104,47%, mais do que dobrando o que era pago em 2007. Vejamos:

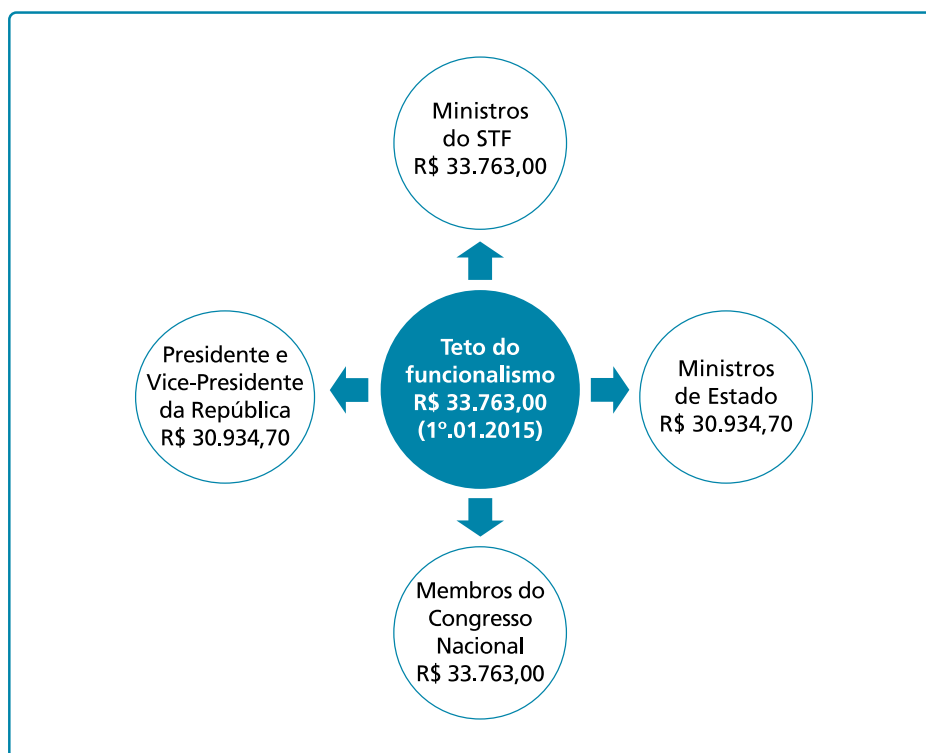
DLG N. 112/2007 — FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL A PARTIR DE 1.º.04.2007	DLG N. 805/2010 — FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL A PARTIR DE 1.º.02.2011	DLG N. 276, DE 18.12.2014 — FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO
---	---	--

		PARTIR DE 1.º.02.2015
■ R\$ 16.512,09	■ R\$ 26.723,13	■ R\$ 33.763,00

Deve-se deixar claro que a Constituição **não** determina que o subsídio dos Deputados e Senadores seja igual ao dos Ministros do STF. O art. 37, XI, estabelece que o **limite remuneratório** dos parlamentares será igual ao subsídio mensal pago aos Ministros do STF, podendo este ser fixado em valor inferior.

Não somos contra a aproximação ou, como neste último momento, a equiparação dos subsídios dos ocupantes dos “Poderes”, lembrando que, apesar de não ser comando constitucional, os parlamentares passaram a ter a mesma remuneração dos Ministros do STF, cujo subsídio mensal é o teto. Apenas achamos que a mesma agilidade deveria ser impressa em relação à aprovação do **salário mínimo**, bem como ao considerável aumento (de 2007 até a última previsão em 2014), buscando-se, ao máximo, atingir, dentro da reserva do possível, os ditames do art. 7.º, IV, da CF/88.

Ilustramos, graficamente, as novas remunerações, trazendo valores de outras autoridades para efeitos comparativos, destacando-se que, conforme visto, nos termos da **Lei n. 13.091/2015**, a partir de **1.º.01.2015**, o teto do funcionalismo (subsídio pago aos Ministros do STF) passou a ser de **R\$ 33.763,00** (cf. *item 22.3.2*):



A título de curiosidade, vejamos o aumento das remunerações em relação às referidas autoridades, lembrando que o subsídio mensal de Ministro do STF (teto) foi estabelecido em R\$ 33.763,00 (Lei n. 13.091/2015) e a sua evolução pode ser encontrada no *item 22.3.2*:

AUTORIDADE	ATO NORMATIVO ANTERIOR/VALOR	ATO NORMATIVO ANTERIOR/VALOR	ATO NORMATIVO EM VIGOR/VALOR
Presidente da República	■ DLG n. 113/2007 ■ R\$ 11.420,21	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 277/2014 ■ R\$ 30.934,70
Vice-Presidente da República	■ DLG n. 113/2007 ■ R\$ 10.748,43	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 277/2014

	■ R\$ 10.748,43	■ R\$ 26.723,13	■ R\$ 30.934,70
Ministros de Estado	■ DLG n. 113/2007 ■ R\$ 10.748,43	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 277/2014 ■ R\$ 30.934,70
Membros do Congresso Nacional	■ DLG n. 112/2007 ■ R\$ 16.512,09	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 276/2014 ■ R\$ 33.763,00

Finalmente, ressaltamos que os parlamentares continuam recebendo, além do subsídio mensal, outros valores, como a cota para o exercício da atividade parlamentar, verba de gabinete, auxílio-moradia, fornecimento de jornais, revistas e publicações técnicas, serviços gráficos, passagens aéreas, atendimento médico e odontológico etc. [12](#)

A **natureza jurídica** dessas verbas deveria ser melhor estudada para verificar se alguma delas tem essência de remuneração, gerando problemas com a regra do teto fixada no art. 37, XI (já que, agora, o subsídio mensal dos parlamentares, além dessas outras verbas, deve respeitar o teto do funcionalismo, conforme visto. Para conhecimento, há entendimento de que incide imposto de renda sobre o total da remuneração do deputado, inclusive sobre o auxílio-moradia, quando pago em espécie).

■ 9.6.2. Verba indenizatória: dever de transparência

De acordo com o art. 1.º, *caput*, do *Ato da Comissão Diretora n. 3/2003 do Senado Federal*, a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar destina-se ao pagamento de despesas mensais realizadas pelos Senadores com

expediente para escritório, com locomoção e com outras despesas diretas e **exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar**.

O **dever** de apresentar os **documentos comprobatórios** das despesas existe desde a publicação do *Ato da Comissão Diretora n. 3/2009*.

A orientação, sem dúvida, direciona-se para os Deputados Federais, destacando-se o *Ato da Mesa n. 43/2009*, que institucionaliza a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) naquela Casa.

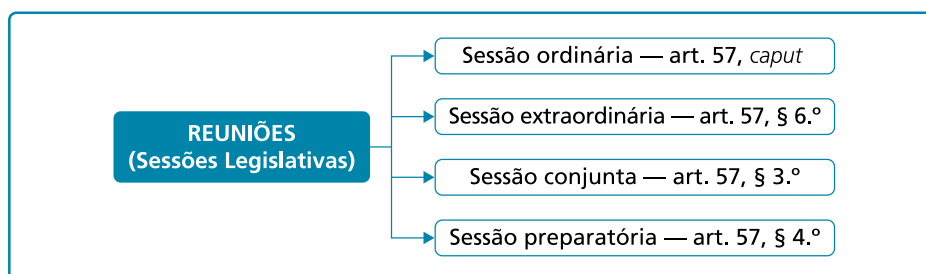
Isso posto, passamos a analisar uma situação concreta envolvendo a negativa de fornecimento dessas verbas pelo Senado Federal para um jornal de grande circulação.

Trata-se do **MS 28.178**, no qual a Empresa *Folha da Manhã S/A* (editora do jornal *Folha de S. Paulo*) solicitou o fornecimento de informações sobre a **verba indenizatória** dos Senadores no período de setembro a dezembro de 2008. O ato coator se caracterizava pela negativa de fornecimento dessas informações sob o argumento de que estão acobertadas pelo sigilo. Apesar da regra atual que consagra o dever de publicidade, na situação concreta dos autos não havia previsão de prestar as informações durante o período em discussão no citado mandado de segurança.

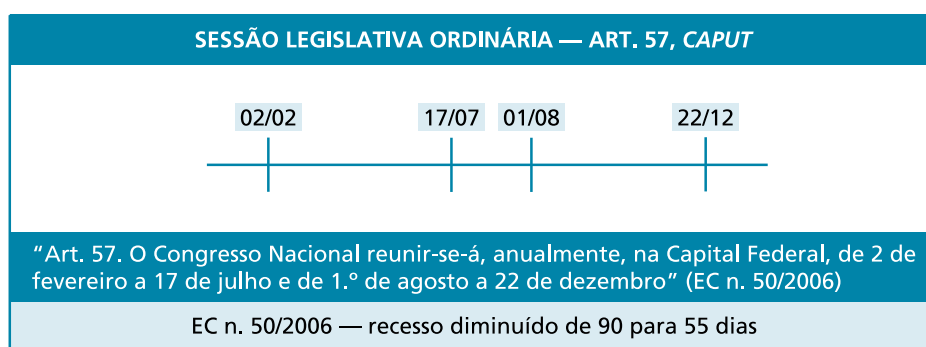
O voto do Min. Roberto Barroso mostrou-se bastante adequado. Conforme divulgado, a **natureza pública** dessa verba “estaria presente tanto na fonte pagadora — o Senado Federal — quanto na finalidade, vinculada ao exercício da representação popular. Nesse contexto, **a regra geral seria a publicidade** e decorreria de um conjunto de normas constitucionais, como o **direito de acesso à informação por parte dos órgãos públicos** (CF, art. 5.º, XXXIII) — especialmente no tocante à documentação governamental (CF, art. 216, § 2.º) —, o **princípio da publicidade** (CF, art. 37, *caput* e § 3.º, II) e o **princípio republicano** (CF, art. 1.º), do qual se originariam os **deveres** de **transparência** e **prestação de contas**, bem como a possibilidade de responsabilização ampla por eventuais irregularidades. Recordou que o art. 1.º, parágrafo único, da CF enuncia que ‘todo o poder emana do povo’. Assim, os órgãos estatais teriam o dever de esclarecer ao seu mandante, titular do poder político, como seriam

dever de esclarecer ao seu mandante, titular do poder político, como seriam usadas as verbas arrecadadas da sociedade para o exercício de suas atividades. Observou que a Constituição ressaltaria a regra da publicidade apenas em relação às informações cujo sigilo fosse imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5.º, XXXIII, parte final) e às que fossem protegidas pela inviolabilidade conferida à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (CF, art. 5.º, X, c/c art. 37, § 3.º, II). Por se tratar de situações excepcionais, **o ônus argumentativo de demonstrar a caracterização de uma dessas circunstâncias incumbiria a quem pretendesse afastar a regra geral da publicidade**” (*Inf. 770/STF*). Nesses termos, em **04.03.2015**, o Plenário do STF concedeu a ordem obrigando a autoridade impetrada a fornecer à impetrante cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória por Senadores da República referentes ao período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 2008 (*Inf. 776/STF*).

■ 9.7. DAS REUNIÕES



■ 9.7.1. Sessão legislativa ordinária



de 14.02.2006, que o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1.º de agosto a 22 de dezembro**. Nesse período, chamado de **sessão legislativa**, os parlamentares se reúnem **ordinariamente**.

Fora desse período, ou seja, de **18 a 31 de julho** e de **23 de dezembro a 1.º de fevereiro**, temos o **recesso parlamentar**, e, havendo necessidade, os parlamentares serão convocados **extraordinariamente**. Como veremos abaixo ao tratar das comissões, durante o recesso parlamentar haverá uma **Comissão representativa do Congresso Nacional**, com atribuições definidas no regimento comum (art. 58, § 4.º).

Sem dúvida, essa primeira novidade trazida pela EC n. 50/2006, qual seja, a redução do recesso parlamentar de 90 para 55 dias, objetiva atender aos anseios e insatisfações da sociedade.

Deve-se notar que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 2.º).

Por fim, tendo definido o que venha a ser **sessão legislativa ordinária** (reunião anual em Brasília do Congresso Nacional, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro), bem como **legislatura** (período de 4 anos que corresponde ao mandato dos Deputados Federais), conclui-se que cada **legislatura** é composta por 4 **sessões legislativas ordinárias**.

■ 9.7.2. Hipóteses de convocação extraordinária

A convocação extraordinária será feita, de acordo com o **art. 57, § 6.º**:

- pelo **Presidente do Senado Federal**: nas hipóteses de decretação de estado de defesa; decretação de intervenção federal; pedido de autorização para a decretação de estado de sítio; e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- pelo **Presidente da República**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006);

cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006);

- pelo **Presidente da Câmara dos Deputados**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006);

- pelo **Presidente do Senado Federal**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006);

- por **requerimento da maioria dos membros de ambas as casas**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006).

Importante observar que, na **sessão legislativa extraordinária**, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8.º do art. 57, sendo **vedado**, ainda, o pagamento de **parcela indenizatória**, em razão da convocação extraordinária (cf. art. 57, § 7.º).

Como se percebe, a **EC n. 50/2006**, também respondendo às críticas da sociedade que condenava, com rigor, o pagamento de parcela indenizatória em valor não superior ao do subsídio mensal, em ato moralizador, **extinguiu o pagamento de qualquer valor extra** em caso de convocação extraordinária.

A vedação contida no art. 57, § 7.º, deve ser entendida como de **reprodução obrigatória** para os parlamentares dos Estados-Membros (art. 27, § 2.º, da CF/88 [13](#)) e do DF (art. 32, § 3.º, da CF/88 [14](#)) e, em nosso entender, também de observância compulsória para os parlamentares municipais, tendo em vista o princípio da **moralidade da legislação** e, acima de tudo, da **simetria**. [15](#)

Nessa linha de moralização, o Congresso Nacional já havia **abolido** o pagamento da **ajuda de custo** durante a convocação extraordinária, mediante alteração do *caput* e revogação do § 1.º do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95 pelo Decreto Legislativo n. 1/2006.

Mas atenção: nos termos do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95, continua devida ao parlamentar, no início e no final previstos para a **sessão legislativa**

vedado o seu pagamento, contudo, na sessão legislativa extraordinária.

A **ajuda de custo** destina-se, a teor do **revogado** § 1.º do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95, à compensação de despesas com transporte e outras imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa.

Portanto, com a novidade trazida pelo Decreto Legislativo n. 1/2006 e pela EC n. 50/2006, durante a convocação extraordinária, **não mais cabe o pagamento de ajuda de custo**, nem mesmo **o pagamento de qualquer parcela indenizatória** em razão da convocação. No entanto, em consonância com a nova redação conferida ao *caput* do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95 (pelo Decreto Legislativo n. 1/2006), ainda persiste o pagamento de **ajuda de custo** durante a **sessão legislativa ordinária**.

Excepcionando a regra geral do art. 57, § 7.º, que limita o Congresso Nacional, na sessão legislativa extraordinária, a deliberar somente sobre a matéria para a qual foi convocado, a **EC n. 32, de 11.09.2001**, trouxe uma única exceção, qual seja, a possibilidade de apreciação de **medidas provisórias** que estiverem em vigor na data da referida convocação extraordinária.

Assim, de acordo com o art. 57, § 8.º, acrescentado, “havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas **automaticamente incluídas na pauta da convocação**”.

■ 9.7.3. Reunião em sessão conjunta

Em determinadas hipóteses, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em **sessão conjunta**. Isso se dará, entre outros casos previstos na Constituição, para (cf. o art. 57, § 3.º):

- I — inaugurar a sessão legislativa;
- II — elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
- III — receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- IV — conhecer do veto e sobre ele deliberar.

■ 9.7.4. Sessão preparatória e Mesas Diretoras

Não obstante já tenhamos observado que a sessão legislativa ordinária só começa em **2 de fevereiro**, cada uma das Casas reunir-se-á em **sessões preparatórias**, a partir de **1.º de fevereiro**, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 anos, **vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente**.

Devemos deixar consignado que essa proibição **não se verifica nas hipóteses de legislaturas distintas** (lembrando ser a legislatura o período de 4 anos). Nesse sentido, o art. 5.º, § 1.º, *RICD*, é expresso ao estabelecer **não ser considerada recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas**.

Para se ter um exemplo, recordamos a recondução do Senador Renan Calheiros, reeleito presidente do Senado Federal para o biênio 2015-2016, após já ter sido Presidente da Casa e, portanto, da Mesa, no biênio anterior.

Verifica-se, então, que excepcionalmente o recesso parlamentar poderá ser de **54**, e não **55** dias, já que, pela regra fixada no art. 57, § 4.º, em referidas hipóteses, o Congresso Nacional será reunido, **ordinariamente**, a partir de 1.º de fevereiro.

As Mesas Diretoras de cada Casa exercem funções administrativas (de polícia, execução e administração), devendo, no tocante à sua constituição, ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa (art. 58, § 1.º).

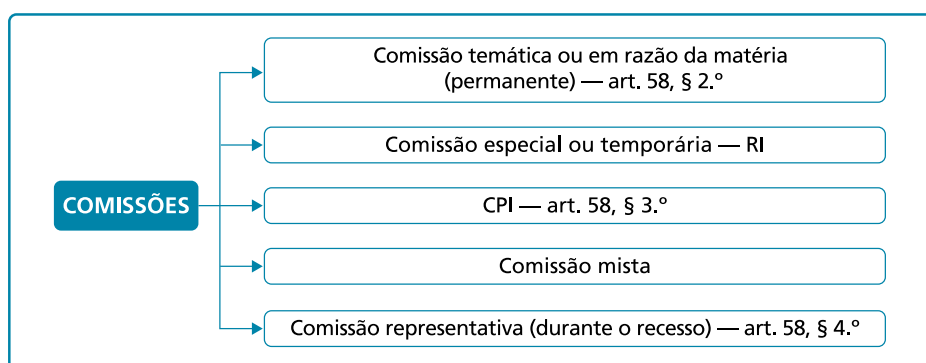
Temos, então, a Mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e a Mesa do Congresso Nacional, sendo a esta última, de acordo com o art. 57, § 5.º, estabelecidas algumas regras:

■ **presidência da Mesa do Congresso Nacional:** Presidente do Senado Federal;

■ **demais cargos da Mesa do Congresso Nacional:** serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal. Dessa forma, se a presidência é ocupada por um membro do Senado Federal (no caso o Presidente do Senado Federal), a 1.^a Vice-presidência será ocupada por um membro da Câmara; o 2.^o Vice-presidente do Senado; o 1.^o Secretário por um membro da Câmara; o 2.^o Secretário por um do Senado; o 3.^o Secretário da Câmara e o 4.^o Secretário do Senado.

■ 9.8. DAS COMISSÕES PARLAMENTARES



José Afonso da Silva define as comissões parlamentares como “organismos constituídos em cada Câmara, composto de número geralmente restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres”. [16](#)

De acordo com o art. 58, as comissões podem ser **permanentes** ou **temporárias** e serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno do Congresso Nacional e de cada Casa, já que existirão comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Estabelece o art. 58, § 1.^o, que na constituição das Mesas e de cada Comissão é assegurada, tanto quanto possível, a **representação proporcional** dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

Passemos, então, a examinar cada uma delas.

■ 9.8.1. Comissão temática ou em razão da matéria (permanentes)

As comissões temáticas estabelecem-se em razão da matéria e são **permanentes**.

De acordo com o art. 58, § 2.º, da CF/88, compete-lhes:

I — discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;

II — realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III — convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições, sob pena de cometer crime de responsabilidade (art. 50);

IV — receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V — solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI — apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Nos termos do art. 72 do *Regimento Interno do Senado Federal*[17](#), para exemplificar, as comissões permanentes, além da Comissão Diretora, são as seguintes:

- Comissão de Assuntos Econômicos — CAE;
- Comissão de Assuntos Sociais — CAS;
- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania — CCJ;
- Comissão de Educação, Cultura e Esporte — CE;
- Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle — CMA;
- Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa — CDH;
- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional — CRE;
- Comissão de Serviços de Infraestrutura — CI;
- Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo — CDR;
- Comissão de Agricultura e Reforma Agrária — CRA;

■ Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática — CCT;

■ Comissão Senado do Futuro — CSF.

Por sua vez, o art. 32 do *Regimento Interno da Câmara dos Deputados* (atualizado até a *Res. n. 1/2015*) define as seguintes comissões permanentes:

■ Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;

■ Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia;

■ Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;

■ Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania;

■ Comissão de Defesa do Consumidor;

■ Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;

■ Comissão de Desenvolvimento Urbano;

■ Comissão de Direitos Humanos e Minorias;

■ Comissão de Educação;

■ Comissão de Finanças e Tributação;

■ Comissão de Fiscalização Financeira e Controle;

■ Comissão de Legislação Participativa;

■ Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

■ Comissão de Minas e Energia;

■ Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional;

■ Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;

■ Comissão de Seguridade Social e Família;

■ Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público;

■ Comissão de Turismo;

- Comissão de Viação e Transportes;
- Comissão de Cultura;
- Comissão do Esporte;
- Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

■ 9.8.2. Comissão especial ou temporária

As comissões especiais são criadas para apreciar uma matéria específica, extinguindo-se com o término da legislatura ou cumprida a finalidade para a qual foram criadas. [18](#)

■ 9.8.3. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

■ 9.8.3.1. Regras gerais

As regras sobre as CPIs estão disciplinadas no art. 58, § 3.º, da CF/88, na Lei n. 1.579, de 18.03.1952, na Lei n. 10.001, de 04.09.2000, na LC n. 105, de 10.01.2001, e nos Regimentos Internos das Casas.

De acordo com as definições regimentais, pode-se afirmar que as CPIs são **comissões temporárias**, destinadas a investigar **fato certo e determinado**.

Entendemos que esse papel desempenhado de **fiscalização** e **controle** da Administração é verdadeira **função típica** do **Poder Legislativo**, tanto que o art. 70, *caput*, da CF/88 estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Ainda, a função fiscalizadora exercida pelo Poder Legislativo consagra a perspectiva dos **freios e contrapesos**, muito bem delimitada na Constituição de

1988.

■ 9.8.3.2. Criação

De acordo com o art. 58, § 3.º, da CF/88, as CPIs serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de **1/3** de seus membros.

Vale dizer, as CPIs somente serão criadas por requerimento de, no mínimo, **171** Deputados (1/3 de 513) e de, também, no mínimo, **27** Senadores (1/3 de 81), em conjunto ou separadamente.

Para sua criação, portanto, 3 **requisitos** indispensáveis deverão ser observados:

- requerimento subscrito por, no mínimo, **1/3** de parlamentares;
- indicação, com precisão, de **fato determinado** a ser apurado na investigação parlamentar;
- indicação de **prazo certo** (temporariedade) para o desenvolvimento dos trabalhos.

■ 9.8.3.3. Direito público subjetivo das minorias

A discussão sobre a temática do **direito público subjetivo das minorias** surgiu no bojo da *CPI do Apagão Aéreo*, instalada para investigar as causas, as consequências e os responsáveis pela crise ocorrida no setor aéreo brasileiro, observados os requisitos do art. 58, § 3.º.

Após ter sido efetivamente instalada, o Plenário da Câmara dos Deputados desconstituiu o ato de criação da CPI. Contra esse ato da Mesa e do presidente da Câmara dos Deputados, foi impetrado o **MS 26.441**. O STF, seguindo o voto do Min. Celso de Mello, determinou a instauração da CPI, sob pena de violação do **direito público subjetivo das minorias**, mesmo contra a vontade da maioria da Casa. Nesse sentido:

“EMENTA: (...). Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro **estatuto constitucional das minorias parlamentares**, cujas prerrogativas — notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar — devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. — A norma inscrita no art. 58, § 3.º, da Constituição da República destina-se a ensejar a **participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa**, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. — O **direito de oposição**, especialmente aquele reconhecido às **minorias legislativas**, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional. — **A maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, § 3.º, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado**. Precedentes: MS 24.847/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. — A ofensa ao direito das minorias parlamentares constitui, em essência, um **desrespeito ao direito do próprio povo**, que também é representado pelos grupos minoritários que atuam nas Casas do Congresso Nacional (...). A **rejeição** de ato de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, **pelo Plenário da Câmara dos Deputados**, ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso interposto por líder de partido político que compõe a maioria congressual, **não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República outorga às minorias que atuam nas Casas do Congresso Nacional**” (MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.04.2007, Plenário, DJE de 18.12.2009).

■ 9.8.3.4. Objeto

A CPI, ao ser instaurada, deve ter por **objeto** a apuração de **fato determinado**.

Considera-se fato determinado, de acordo com o art. 35, § 1.º, do *RICD*, o acontecimento de relevante interesse para a **vida pública** e a **ordem constitucional, legal, econômica e social do País**, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão, **não** podendo, portanto, a CPI ser instaurada para apurar fato **exclusivamente privado** ou **de caráter pessoal**.

Consoante relatado pelo Ministro Paulo Brossard, “são amplos os poderes da comissão parlamentar de inquérito, pois são os necessários e úteis para o cabal desempenho de suas atribuições. Contudo, **não são ilimitados**. Toda autoridade, seja ela qual for, está sujeita à Constituição. O Poder Legislativo também e com ele as suas comissões. A comissão parlamentar de inquérito encontra na jurisdição constitucional do Congresso seus limites. Por uma necessidade funcional, a **comissão parlamentar de inquérito não tem poderes universais**, mas limitados a **fatos determinados**, o que não quer dizer não possa haver tantas comissões quantas as necessárias para realizar as investigações recomendáveis, e que outros fatos, inicialmente imprevisos, não possam ser aditados aos objetivos da comissão de inquérito, já em ação. O poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um poder instrumental ou ancilar relacionado com as atribuições do Poder Legislativo” (HC 71.039/RJ, *DJ* de 06.12.1996, p. 48708, *Ement.* v. 1853-02, p. 278, j. 07.04.1994, Tribunal Pleno/STF).

Nesse sentido, diante de um **mesmo fato**, pode ser criada CPI na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em conjunto, a CPMI (comissão parlamentar mista de inquérito), ou, ainda, a investigação poderá ser conduzida pelo Judiciário, por outros órgãos ou, até, por CPIs nos outros entes federativos, se houver interesse comum, devendo cada qual atuar nos limites de sua competência.

O art. 146 do *RISF* estabelece, contudo, que não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes:

- à Câmara dos Deputados;
- às atribuições do Poder Judiciário;
- aos Estados.

Observa-se, também, a possibilidade de instauração de **CPIs simultâneas** dentro de uma **mesma Casa**, sendo que o *Regimento Interno da Câmara dos Deputados*, no seu art. 35, § 4.º, determinou o **limite** de 5, restrição essa declarada **constitucional** pelo STF por estar em consonância com os incs. III e IV do art. 51 da CF/88, que conferem à Câmara “a prerrogativa de elaborar o seu regimento interno e dispor sobre sua organização. Tais competências são um poder-dever que permite regular o exercício de suas atividades constitucionais” (ADI 1.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 19.10.2000).

■ 9.8.3.5. **Prazo**

A CPI, por ser uma comissão **temporária**, deve ser criada por **prazo certo**.

A teor do art. 35, § 3.º, do *RICD*, a CPI na Câmara, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade do prazo, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

Estabelecendo requisito temporal, o art. 76 do *RISF*, por sua vez, prescreve que as **comissões temporárias**, e, no caso, a CPI é uma comissão temporária, se extinguem:

- pela conclusão da sua tarefa; ou
- ao término do respectivo prazo; e
- ao término da sessão legislativa ordinária.

Os §§ 1.º e 4.º do art. 76 estabelecem, contudo, ser lícito à comissão que não tenha concluído a sua tarefa requerer a **prorrogação** do respectivo prazo, sendo

que, no caso da CPI, essa prorrogação **não** poderá ultrapassar o período da **legislatura** em que for criada.

■ 9.8.3.6. **Poderes**

As CPIs terão poderes de **investigação**, próprios das autoridades **judiciais**, além de outros previstos nos regimentos internos das Casas. [19](#)

A *comissão parlamentar de inquérito* realiza, assim, verdadeira **investigação**, materializada no **inquérito parlamentar**, que se qualifica como um “... procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria” (MS 23.652, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2000).

Em razão dos **poderes instrutórios** que lhe foram conferidos, à semelhança dos **juízos de instrução**, o art. 2.º da Lei n. 1.579/52 estabelece que, no exercício de suas atribuições, poderão as CPIs determinar as diligências que reportarem necessárias e requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e autárquicas informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença.

Consoante já decidiu o STF, a CPI pode, por **autoridade própria**, ou seja, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, sempre por **decisão fundamentada** e **motivada**, observadas todas as formalidades legais, determinar:

- **quebra do sigilo fiscal**;
- **quebra do sigilo bancário**;
- **quebra do sigilo de dados**; neste último caso, destaque-se o **sigilo dos dados telefônicos**. [20](#)

Explicitando este último ponto, conforme se destaca abaixo, dentro da ideia de **postulado de reserva constitucional de jurisdição**, o que a CPI **não** tem é a competência para **quebra do sigilo da comunicação telefônica**

(interceptação telefônica).

No entanto, pode a CPI requerer a quebra de **registros telefônicos pretéritos**, ou seja, de conversas já ocorridas em determinado período. Nesse sentido, lapidares as palavras do Ministro Celso de Mello:

“**A quebra do sigilo constitui poder inerente à competência investigatória das comissões parlamentares de inquérito** — O *sigilo bancário*, o *sigilo fiscal* e o *sigilo telefônico* (sigilo este que incide sobre os **dados/registros telefônicos** e que **não** se identifica com a **inviolabilidade das comunicações telefônicas**) — ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5.º, X, da Carta Política — não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às CPIs, eis que o *ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar*. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por **autoridade própria**, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico (dos dados e registros, acrescente-se), relativamente **a pessoas por elas investigadas**, devem **demonstrar**, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), **justificando a necessidade** de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5.º, XXXV)” (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12.05.2000, p. 20, *Ement.* v. 1990-01, p. 86 — original sem grifos).

Convém destacar o § 1.º do art. 4.º da **LC n. 105/2001**, 21 ao estabelecer que as **CPIs**, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, **obterão** as **informações** e os **documentos sigilosos** de que necessitarem **diretamente** das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, devendo referidas solicitações ser previamente aprovadas pelo Plenário da Câmara dos

Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito.

Dentro do conceito de poder investigatório da CPI, ela ainda tem o direito de:

■ **ouvir testemunhas, sob pena de condução coercitiva:** as testemunhas prestarão compromisso de dizer a verdade, sob pena de **falso testemunho**. A elas é também assegurada a prerrogativa contra a autoincriminação, garantindo-se o **direito ao silêncio**, ou quando deva guardar sigilo em razão de função, ministério, ofício ou profissão, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho (arts. 207 do CPP e 406, II, do CPC/73 — com correspondência no art. 388, II, CPC/2015);²²

■ **ouvir investigados ou indiciados:** a CPI, contudo, deverá respeitar, retome-se, o **direito ao silêncio do investigado ou indiciado**, que poderá deixar de responder às perguntas que possam incriminá-lo (HC 80.584-PA, Rel. Min. Néri da Silveira, 08.03.2001).

Esse limite ganhou relevância em razão das diversas CPIs para a investigação dos supostos escândalos que envolveram o governo Lula, principalmente durante os meses de julho e agosto de 2005, tendo sido expedidos diversos “salvo-condutos” possibilitando ao requerente, no interrogatório da CPI, ser tratado como **investigado**.

Para se ter um exemplo, citamos o voto da Ministra Ellen Gracie, que concedeu *habeas corpus* preventivo ao publicitário *Marcos Valério Fernandes de Souza* para depor na *Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios*, na Câmara dos Deputados, na condição de investigado.

Argumenta a Ministra que “... às Comissões Parlamentares de Inquérito poder-se-ão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados da **garantia constitucional da não autoincriminação**, que tem sua manifestação mais eloquente no **direito ao silêncio dos acusados** (HC 79.812, Celso de Mello; HC 79.244, Sepúlveda Pertence; HC 84.335, Ellen Gracie; HC 83.775, Joaquim Barbosa; HC 85.836, Carlos Velloso). Diante do exposto, defiro a liminar para que o paciente seja

dispensado de firmar termo de compromisso legal de testemunha, ficando-lhe assegurado o direito de se calar sempre que a resposta à pergunta, a critério dele, paciente, ou de seu advogado, possa atingir a garantia constitucional de não autoincriminação. Comunique-se com urgência. Expeça-se salvo-conduto. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2005” (HC 86.232/DF, *DJ* de 1.º.08.2005, p. 39).

Nesse sentido, destacamos os salvo-condutos expedidos em favor do ex-tesoureiro e do ex-secretário-geral do Partido dos Trabalhadores (PT), Delúbio Soares e Silvio José Pereira, para deporem na *CPI Mista dos Correios*, na condição de investigados (HC 86.319).

Outrossim, muito bem fundamentada a decisão proferida pelo Ministro Peluso ao deferir liminar requerida em favor de Waldomiro Diniz, para que, sempre que convocado a depor perante a *Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos*, tenha o “... direito de permanecer em **silêncio** se a resposta à pergunta implicar risco de autoincriminação. Além disso, ele poderá ser **acompanhado de advogado** e terá garantido o **direito de não ser preso ao invocar o direito constitucional de não se autoincriminar**” (*Notícias STF*, 10.08.2005, HC 86.426).

Analisando a doutrina alemã, também assim a decisão do Ministro Gilmar Mendes, que, em sede de cautelar, expediu salvo-conduto para o presidente do Grupo Opportunity, Daniel Valente Dantas, permanecer calado durante depoimento à *CPMI dos Correios* sobre os fatos que possam implicar a sua autoincriminação (*Notícias STF*, 20.09.2005, HC 86.724).

■ **E como fica a situação de esposa de investigado?**

Tivemos um caso concreto analisado pelo STF no **HC 86.355**, impetrado por Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, esposa do publicitário Marcos Valério. Segundo noticiado, o Ministro Jobim “... afirmou que Renilda Souza deve atender à convocação da CPMI, nos dias e horas marcados, mas não é obrigada a assinar o compromisso de dizer a verdade. No entanto, ela deverá ‘responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas’. O Ministro observou que, de acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro (artigos 203, 206 e

208 combinados), **a testemunha não pode se eximir da obrigação de depor**, mas, sendo **cônjuge** de um dos **investigados**, **não é obrigada a firmar o compromisso de dizer a verdade**” (*Notícias STF*, 25.07.2005, em que se pode verificar a íntegra da decisão).

Lembramos, ainda, o dever de a CPI permitir a presença de **advogados**, exercendo a defesa técnica, com todas as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da Advocacia.

■ 9.8.3.7. *O princípio da separação de “poderes” e a impossibilidade de a CPI investigar atos de conteúdo jurisdicional*

Deve-se consignar que o **princípio da separação de poderes** serve de baliza e limitação material para a atuação parlamentar, e, desse modo, a CPI **não** tem poderes para investigar atos de **conteúdo jurisdicional**, não podendo, portanto, rever os fundamentos de uma sentença judicial.

Apesar disso, o Min. Celso de Mello adverte: “... isso não significa, porém, que todos os atos do Poder Judiciário estejam excluídos do âmbito de incidência da investigação parlamentar. Na verdade, entendo que se revela constitucionalmente **lícito**, a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, **investigar atos de caráter não jurisdicional emanados do Poder Judiciário**, de seus **integrantes** ou de seus **servidores**, especialmente se se cuidar de atos, que, por efeito de expressa determinação constitucional, se exponham à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Legislativo (CF, arts. 70 e 71) ou que traduzam comportamentos configuradores de infrações político-administrativas eventualmente praticadas por Juízes do STF (Lei n. 1.079/50, art. 39), que se acham sujeitos, em processo de *impeachment*, à jurisdição política do Senado da República (CF, art. 52, II)” (voto no **HC 79.441**, j. 15.09.2000, fls. 322-323).

■ 9.8.3.8. *Postulado de reserva constitucional de jurisdição*

Muito embora o constituinte originário tenha conferido poderes à CPI, restritos à investigação, referidos poderes não são absolutos, devendo sempre ser respeitado o **postulado da reserva constitucional de jurisdição**.

Conforme definiu o Ministro Celso de Mello, “o **postulado da reserva constitucional de jurisdição** importa em submeter, à esfera única de **decisão dos magistrados**, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, **somente pode emanar do juiz**, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja eventualmente atribuído o exercício de ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’” (MS 23.452).

Isso significa que a CPI **não** poderá praticar determinados **atos de jurisdição** atribuídos exclusivamente ao **Poder Judiciário**, vale dizer, atos **propriamente jurisdicionais**. **Veda-se**, portanto, à CPI:

■ **diligência de busca domiciliar**: a busca domiciliar, nos termos do art. 5.º, XI, da CF, verificar-se-á com o consentimento do morador, sendo que, na sua falta, ninguém poderá adentrar na casa, asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, durante o dia ou à noite, mas, durante o dia, somente por **determinação judicial**, não podendo a CPI tomar para si essa competência, que é reservada ao Poder Judiciário; [23](#)

■ **quebra do sigilo das comunicações telefônicas (interceptação telefônica)**: de acordo com o art. 5.º, XII, a quebra do sigilo telefônico somente poderá ser verificada por **ordem judicial** (e não da CPI ou qualquer outro órgão), para fins de **investigação criminal** ou **instrução processual penal**;

■ **ordem de prisão, salvo no caso de flagrante delito, por exemplo, por crime de falso testemunho** (STF, HC 75.287-0, DJ de 30.04.1997, p. 16302): isso porque a regra geral sobre a prisão prevista no art. 5.º, LXI, determina que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de **autoridade judiciária** (e não CPI) competente, ressalvados os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei — prisão disciplinar (*vide* RDA 196/195, Rel. Min. Celso

de Mello; *RDA* 199/205, Rel. Min. Paulo Brossard) e a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida durante o **estado de defesa** e não superior a 10 dias, devendo ser imediatamente comunicada ao juiz competente (art. 136, § 3.º, I a IV).

Outra questão, que pode ser indagada nas provas e já resolvida pelo STF, diz respeito às **medidas assecuratórias**, pertinentes à **eficácia de eventual sentença condenatória**.

Em primoroso trabalho sobre as CPIs, Cássio Juvenal Faria assevera que “os provimentos dessa natureza, como o sequestro, o arresto e a hipoteca legal, previstos nos arts. 125 e ss. do CPP, bem como a decretação da indisponibilidade de bens de uma pessoa, medida que se insere no **poder geral de cautela do juiz**, são atos **tipicamente jurisdicionais**, próprios do exercício da jurisdição cautelar, quando se destinam a assegurar a eficácia de eventual sentença condenatória, apartando-se, assim, por completo, dos poderes da comissão parlamentar de inquérito, que são apenas de ‘investigação’”.²⁴

■ 9.8.3.9. *Postulado da colegialidade*

De acordo com a doutrina e a jurisprudência do STF, a **eficácia** das deliberações dos parlamentares integrantes da CPI deve observar o **postulado da colegialidade**, devendo as decisões ser tomadas pela maioria dos votos e não isoladamente. Nesse sentido:

“O **princípio da colegialidade** traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (‘disclosure’) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se **nula**” (**MS 24.817**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.02.2005, Plenário, *DJE* de

06.11.2009).

■ 9.8.3.10. **Motivação**

Toda **deliberação da CPI** deverá ser **motivada**, sob pena de padecer do **vício de ineficácia** (art. 93, IX, da CF).

Para o Ministro Celso de Mello, “as deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se *írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal*” (MS 23.452/RJ, DJ de 12.05.2000, p. 20).

■ 9.8.3.11. **Conclusões**

As CPIs não podem nunca impor penalidades ou condenações. Os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional encaminharão o **relatório** da CPI respectiva e a resolução que o aprovar aos chefes do Ministério Público da União ou dos Estados ou, ainda, às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência e, assim, existindo elementos, para que promovam a responsabilização civil, administrativa ou criminal dos infratores.

Dependendo dos limites da atuação ministerial (na medida em que ao Ministério Público está vedada a representação judicial de entidades públicas — art. 129, IX), entendemos que o relatório deva ser encaminhado, também, para a Advocacia-Geral da União e outros órgãos que exercem a representação judicial e consultoria das respectivas unidades federadas, para que promovam eventual responsabilização civil.

Deixando mais claro e disciplinando a matéria, o art. 37 do *RICD* determina,

ao término dos trabalhos, o encaminhamento de **relatório circunstanciado**, com as **conclusões**:

■ à **Mesa**, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação, que será incluída na Ordem do Dia dentro de cinco sessões;

■ à **Advocacia-Geral da União** ou ao **Ministério Público**, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

■ ao **Poder Executivo**, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do art. 37, §§ 2.º a 6.º, da Constituição Federal e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

■ à **Comissão Permanente** que tenha maior pertinência com a matéria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;

■ à **Comissão Mista Permanente** de que trata o art. 166, § 1.º, da Constituição Federal;

■ ao **Tribunal de Contas da União**, para as providências previstas no art. 71 da mesma Carta.

O art. 1.º da Lei n. 10.001, de 04.09.2000, determinou que os Presidentes da CD, do SF ou do CN encaminharão o **relatório** da CPI respectiva, e a resolução que o aprovar, aos chefes do MP da União ou dos Estados, ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência, na medida em que a CPI, como vimos, só investiga, não julga nem aplica qualquer tipo de penalidade.

Referida autoridade, a quem for encaminhada a resolução, que aprovou o relatório da CPI, informará ao remetente, no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou a justificativa pela omissão, sendo que a autoridade que presidir processo ou procedimento, administrativo ou judicial, instaurado em decorrência de conclusões de CPI, comunicará, semestralmente, a fase em que se encontra,

até a sua conclusão, garantindo-se ao referido processo ou ao procedimento **prioridade** sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a pedido de *habeas corpus*, *habeas data* e mandado de segurança, sujeitando-se a autoridade às sanções administrativas, civis e penais em razão de eventual descumprimento das normas da lei em comento.

■ 9.8.3.12. Competência originária do STF

É da **competência originária** do **STF** processar e julgar **MS** e **HC** impetrados contra CPIs constituídas no âmbito do **Congresso Nacional ou de quaisquer de suas Casas**.

Isso porque, conforme já decidiu a Suprema Corte, “... a Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a *longa manus* do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou de *habeas corpus*, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’)” (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 12.05.2000, p. 20).

■ 9.8.3.13. A regra da prejudicialidade

A jurisprudência do STF, **por regra**, determina a **prejudicialidade** das “... ações de mandado de segurança e de *habeas corpus*, sempre que — impetrados tais *writs* constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito — vierem estas a extinguir-se, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da aprovação, ou não, de seu relatório final” (MS 23.852-QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.06.2001, e julgados mais recentes, como HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 08.04.2010, MS 25.459-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04.02.2010 etc.).

Existe, contudo, um importante precedente no qual o STF **não acatou a jurisprudência dominante da prejudicialidade**.

Trata-se da **ACO 622**, ação popular que busca declarar a nulidade da *Res. n. 507/2001*, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se instituiu CPI para apurar as causas do acidente da plataforma P-36 da PETROBRAS, localizada na Bacia de Campos.

Apesar de a CPI ter **encerrado os trabalhos**, o Min. Ricardo Lewandowski, que considerava a ação prejudicada, reconsiderou a decisão, na medida em que o relatório da CPI fazia diversas recomendações, inclusive para que o Ministério Público investigasse o fato.

■ 9.8.3.14. *CPIs estaduais e quebra do sigilo bancário*

Como se sabe, não há expressa previsão constitucional para a criação de *CPIs não federais*.

O art. 58, § 3.º, conforme visto, refere-se apenas e expressamente à criação de CPIs no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de ambas as Casas, no caso, a CPMI (*Comissão Parlamentar Mista de Inquérito*).

A grande questão que surge é definir a **possibilidade** de criação dessas CPIs em **âmbito não federal** e, o mais importante, a **amplitude de seus poderes de investigação** que são, pela ideia de simetria, próprios das autoridades **judiciais**.

■ **a amplitude de atuação das CPIs estaduais e a decisão inédita de não prejudicialidade**

A possibilidade de criação de CPIs em âmbito estadual, distrital e municipal, e, assim, o exercício da **função fiscalizadora**, decorre da ideia de **equilíbrio do pacto federativo** e do **princípio da separação de poderes**, parecendo razoável que cada CPI cuide de problemas afetos à sua amplitude, vale dizer, a CPI federal fiscalizaria a Administração federal, a CPI estadual, a do respectivo Estado e assim por diante.

Esse tema da amplitude da CPI **ainda está para ser mais bem delimitado** pelo STF, especialmente no julgamento da **ACO 622**, ação popular que, conforme referido, busca declarar a nulidade da *Res. n. 507/2001*, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se instituiu **CPI**

para apurar as causas do acidente da **plataforma P-36 da PETROBRAS**, localizada na Bacia de Campos.

Sustenta-se na referida ação (originária no STF diante da ideia de conflito federativo, nos termos do art. 102, I, “f”) que a Assembleia Legislativa do RJ **não** teria **competência investigatória** sobre o fato, já que há **nítido interesse da União**, notadamente por estar a plataforma em **mar territorial** e por envolver a **PETROBRAS**.

Conforme mencionamos acima, a CPI estadual encerrou os seus trabalhos e o STF, mesmo assim, **não acatou a jurisprudência da prejudicialidade da ação**, aguardando-se o julgamento de mérito (cf. ACO 622 QO/RJ, Rel. orig. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.11.2007, *Inf. 487/STF* — **matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Outro precedente interessante, no sentido da amplitude de atuação das CPIs, diz respeito ao julgamento, em sede de cautelar, do **MS 31.689**, impetrado pelo **Governador do Estado de Goiás**, assegurando-lhe, como ato legítimo, a recusa a comparecer, quer como testemunha, quer como investigado, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (**federal**). Tal julgamento envolve as *Operações Vegas e Monte Carlo* e apura atos praticados por *Carlinhos Cachoeira* (cautelar deferida monocraticamente em 15.11.2012).

Isso porque, anotou o Min. Marco Aurélio, a interpretação a ser dada ao art. 49, X, é no sentido de que o Congresso Nacional teria a atribuição de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo da **esfera federal**.

Dessa forma, partindo de precedentes, também em sede de cautelar, fixados nos HCs 95.259 e 80.511, referido Ministro sustentou a “tese da impossibilidade de as comissões (federais, acrescente-se) inquirirem autoridades estaduais e municipais, de quaisquer dos poderes, em virtude da autonomia político-administrativa de tais entes” (mérito do MS não apreciado tendo em vista a perda superveniente do objeto em razão do encerramento dos trabalhos da CPI — decisão proferida em 25.10.2013).

■ **poderes: a questão específica da quebra do sigilo bancário**

Em relação aos poderes das CPIs, a questão mais tormentosa é se seria

possível a **quebra de sigilo bancário pela CPI não federal**.

Existem precedentes admitindo o poder de quebra do sigilo fiscal pela **CPI estadual**, desde que, naturalmente, **fundamentado** o pedido. Nessa linha:

“Ação cível originária. Mandado de segurança. **Quebra de sigilo de dados bancários determinada por CPI de Assembleia Legislativa**. Recusa de seu cumprimento pelo Banco Central do Brasil. LC 105/2001. Potencial conflito federativo (cf. ACO 730-QO). Federação. Inteligência. Observância obrigatória, pelos Estados-membros, de aspectos fundamentais decorrentes do princípio da separação de poderes previsto na CF de 1988. **Função fiscalizadora exercida pelo Poder Legislativo**. Mecanismo essencial do sistema de *checks-and-counterchecks* adotado pela CF de 1988. Vedação da utilização desse mecanismo de controle pelos órgãos legislativos dos Estados-membros. Impossibilidade. Violação do equilíbrio federativo e da separação de Poderes. **Poderes de CPI estadual: ainda que seja omissa a LC 105/2001, podem essas comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados bancários, com base no art. 58, § 3.º, da Constituição**” (ACO 730, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 22.09.2004, Plenário, *DJ* de 11.11.2005).

Em certa passagem de seu voto, o Relator destaca argumentação do Min. Sepúlveda Pertence no julgamento da **ADI 98** (j. 18.12.1997), que sugere “... uma terceira modalidade de limitações à autonomia constitucional dos Estados: além dos grandes princípios e das vedações — esses e aqueles, implícitos ou explícitos — não de acrescentar-se às **normas constitucionais centrais** que, não tendo o alcance dos princípios, nem o conteúdo negativo das vedações, são, não obstante, de **absorção compulsória — com ou sem reprodução expressa — no ordenamento parcial dos Estados e Municípios**’. Entendo que a possibilidade de criação de comissões parlamentares de inquérito seja uma dessas normas de absorção compulsória nos Estados-Membros, destinada a garantir o potencial do poder legislativo em sua função de fiscal da administração”.

O tema, amplamente discutido na referida **ACO 730**, cujo resultado foi bastante apertado, por **6 x 5** (*lembrando que a composição, à época, era*

totalmente distinta da atual), voltou a ser analisado pelo STF, no julgamento da **ACO 1.271** (conhecida como *mandado de segurança*), tendo havido os votos do Min. Joaquim Barbosa (que concedia a ordem) e do Min. Eros Grau (que a denegava), quando, em 11.03.2010, houve pedido de vista pelo Min. Dias Toffoli, devolvido em 09.05.2011 (cf. *Inf. 578/STF* — **matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Na referida ação, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro atacava ato do chefe da *Superintendência Regional da Receita Federal*, que, diante de pedido formulado pela “CPI das Milícias”, negou o fornecimento de informações fiscais a respeito dos investigados, com base no **dever de sigilo fiscal**, uma vez que as atribuições conferidas pelo art. 58, § 3.º, às CPIs federais não se estenderiam às CPIs no âmbito estadual.

Segundo noticiado, “o relator assinalou que, numa federação, a outorga de competência no campo da fiscalização aos entes federados que não compõem a União seria **ínsita ao tipo de equilíbrio do pacto federativo que se tem por emanado da Constituição**. Registrou que, mesmo em uma **federação** tendente à concentração, como é o caso da brasileira, seria **imprescindível assegurar acervo mínimo de instrumentos para que cada um dos Poderes**, no âmbito do respectivo ente federado e nos limites legais, **pudesse exercer com plenitude seu dever de restringir a atividade inadequada, ilegal, inconstitucional** que porventura fosse praticada por representante de outro Poder. Considerou que o fato de o art. 58, § 3.º, da CF se referir literalmente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal não restringiria, por si só, o alcance do dispositivo às entidades federais. Afirmou que, por uma questão de **simetria**, as aptidões essenciais ao exercício da função de controle pelo Legislativo da União deveriam ser adaptadas à realidade dos Estados-membros e do Distrito Federal, respeitados sempre os âmbitos de atuação de cada um, salientando que, salvo momentos pontuais de instabilidade institucional, a União não poderia substituir o Estado-membro na representação da vontade de seus cidadãos e no exercício da competência que a Constituição lhes assegura. Enfatizou que os Estados-membros e o Distrito Federal estariam representados politicamente na formação

da vontade nacional, de modo que não se poderia cogitar de qualquer hierarquia entre os entes federados. Citou, ainda, disposição da Constituição do Estado do Rio de Janeiro acerca dos poderes de investigação de comissão parlamentar de inquérito...” (*Inf. 578/STF*).

Em **12.02.2014**, contudo, o Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o pedido formulado na **ACO 1.271**, tendo em vista o encerramento dos trabalhos da CPI, votando, assim, pela **prejudicialidade** da ação por perda superveniente do seu objeto.

O tema, certamente, precisará ser mais bem debatido pela atual composição da Corte. No entanto, entendemos que o voto do Min. Dias Toffoli, apresentado para efeitos meramente históricos (já que se reconheceu a prejudicialidade da ação), poderá servir de segura orientação para decisões futuras.

Entendeu o Ministro que “a quebra de sigilo fiscal pelas comissões parlamentares de inquérito constitui **instrumento inerente ao exercício da função fiscalizadora insita aos órgãos legislativos** e, como tal, dela também podem fazer uso as CPIs instituídas pelas Assembleias Legislativas e pela Câmara Distrital, desde que observados, em resumo, os seguintes requisitos:

- deve dar-se mediante deliberação colegiada devidamente fundamentada;
- deve haver pertinência entre o objeto da investigação e as informações requisitadas, sendo necessário que se indique fato concreto que justifique tal medida excepcional;
- a atuação da comissão parlamentar estadual deve restringir-se à área de competência constitucional do Poder Legislativo do Estado, somente sendo investigáveis por ele os fatos que possam ser objeto de disciplina em lei, de controle ou de fiscalização parlamentar estadual;
- os dados obtidos podem ser usados somente no âmbito da investigação que lhe deu causa, devendo haver, obrigatoriamente, a preservação da confidencialidade dos dados fiscais, bancários e telefônicos repassados ao parlamento estadual”.

Finalmente, destacamos que, em outra decisão, o Min. Joaquim Barbosa concedeu liminar autorizando a **transferência de informações protegidas por**

sigilo fiscal para a CPI no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, que investiga supostas irregularidades e fraudes praticadas contra cerca de 3.000 mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários do Estado de São Paulo — BANCOOP (**MS 29.046**, liminar proferida em 13.08.2010. Referido mandado de segurança, em 04.11.2011, foi julgado prejudicado, haja vista que a CPI encerrou os seus trabalhos).

Essa parece ser a melhor interpretação e na linha do que o STF já vinha decidindo (ACO 730), sob pena de se esvaziar o papel das CPIs estaduais.

■ **a questão concreta sobre a quebra do sigilo bancário (art. 5.º, X, versus art. 145, § 1.º)**

A questão concreta sobre a *quebra do sigilo bancário* e a discussão acerca da necessidade ou não de **autorização judicial** foi decidida pelo STF no julgamento do **RE 389.808** (j. **15.12.2010**).

A discussão surgiu em decorrência de comunicado feito pelo *Banco Santander* a determinada empresa, informando que a Delegacia da Receita Federal do Brasil, partindo de *mandado de procedimento fiscal* e com base na LC n. 105/2001, havia determinado àquela instituição financeira a entrega de informações sobre movimentação bancária da empresa durante o período de 1998 a julho de 2001.

Diante dessa notícia, a empresa buscou o Judiciário e, após várias medidas, a decisão final veio do STF, que, no caso concreto, por **5 x 4**, concluiu pela necessidade de **autorização judicial** para a quebra de sigilo bancário, por se tratar de verdadeira **cláusula de reserva de jurisdição**, não tendo, portanto, o Fisco esse poder. Vejamos:

“EMENTA: SIGILO DE DADOS — AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5.º da Constituição Federal, a **regra** é a privacidade quanto à **correspondência**, às **comunicações telegráficas**, aos **dados** e às **comunicações**, ficando a exceção — a quebra do sigilo — submetida ao crivo de órgão equidistante — o **Judiciário** — e, mesmo assim, **para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal**. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS — RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da

República norma legal atribuindo à Receita Federal — parte na relação jurídico-tributária — o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte” (RE 389.808, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.12.2010, Plenário, DJE de 10.05.2011).

O Ministro Celso de Mello, em seu voto (inclusive, na AC 33), fala em um verdadeiro “**‘estatuto constitucional do contribuinte’** — consubstanciador de direitos e limitações **oponíveis ao poder impositivo** do Estado”, destacando-se, no caso, o **direito à intimidade** e à **privacidade (art. 5.º, X)**.

Afirma, ainda, que as garantias não são absolutas. Aliás, nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto, devendo, na hipótese de colisão, ser feito juízo de **ponderação**.

Portanto, para eventual quebra de sigilo bancário, é imprescindível “... a existência de **causa provável**, vale dizer, de **fundada suspeita** quanto à ocorrência de fato cuja apuração resulte exigida pelo interesse público. Na realidade, sem **causa provável**, não se justifica, sob pena de inadmissível consagração do arbítrio estatal e de inaceitável opressão do indivíduo pelo Poder Público, a ‘*disclosure*’ das contas bancárias, eis que a **decretação da quebra do sigilo não pode converter-se num instrumento de indiscriminada e ordinária devassa da vida financeira das pessoas em geral**”.

E, ao final, conclui Celso de Mello: “sendo assim, Senhor Presidente, e tendo em consideração as razões expostas, entendo que a *decretação da quebra do sigilo bancário*, ressalvada a **competência extraordinária das CPIs (CF, art. 58, § 3.º)**, pressupõe, sempre, a existência de **ordem judicial**, sem o que não se imporá à instituição financeira o dever de fornecer, seja à *administração tributária*, seja ao *Ministério Público*, seja, ainda, à *Polícia Judiciária*, as informações que lhe tenham sido solicitadas”.

Assim, podemos esquematizar:

■ **possibilidade de quebra do sigilo bancário:** o Poder Judiciário e as CPIs (federais, estaduais e distritais), que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais;

■ **não podem quebrar o sigilo bancário, devendo solicitar**

autorização judiciária: Administração Tributária, Ministério Público, Polícia Judiciária e as CPIs municipais (cf. *item 9.8.3.16*).

Dessa forma, em sendo o direito de quebra do sigilo assegurado às *CPIs federais*, na medida em que elas têm “**poder de investigação próprio das autoridades judiciais**” (art. 58, § 3.º), necessariamente, dentro da ideia de **simetria** e de **autonomia federativa**, esses poderes também devem ser assegurados às **CPIs estaduais**.

■ 9.8.3.15. *CPIs distritais*

E a discussão em relação às CPIs no âmbito da **Câmara Legislativa do DF?**

Apesar de ter o Distrito Federal a sua autonomia parcialmente tutelada pela União — e já discutimos a sua amplitude enquanto verdadeiro ente federativo —, parece, sim, razoável, que o mesmo entendimento que se dê aos Estados seja estendido para o DF, até porque, muito embora a sua posição particular na Federação, o DF se aproxima muito mais dos Estados que dos Municípios (por exemplo, cf. art. 32, § 2.º, que faz coincidir as eleições do Executivo Distrital com a dos Estados-Membros, e art. 32, § 3.º, que determina a aplicação do art. 27 — que trata dos Estados —, aos Deputados Distritais).

Além do mais, o DF tem representação na Federação, já que elegerá 3 Senadores da República (art. 46).

Entendemos, portanto, que, se o STF confirmar o poder de quebra do sigilo bancário pelas CPIs estaduais, simetricamente à regra federal, necessariamente deverá reconhecer esse poder às CPIs distritais (**matéria pendente**).

■ 9.8.3.16. *CPIs municipais*

E as CPIs no âmbito da **Câmara dos Vereadores, podem quebrar sigilo bancário?**

Poderíamos considerar outros argumentos, como *o risco de abuso por parte das referidas CPIs*, sustentado por alguns autores. Porém, preferimos ficar com

uma argumentação puramente jurídica e técnica.

Aqui — e o tema da *disclosure* ainda precisa ser mais bem debatido pelo STF —, entendemos, contudo, que a Câmara dos Vereadores, apesar de poder instaurar CPI, seguindo o modelo federal, **não terá, por si, o poder de quebra do sigilo bancário**.

Não estamos dizendo que a CPI não poderá investigar, até porque é função do Legislativo a fiscalização e o controle da administração pública.

Estamos sugerindo que, na hipótese de quebra de sigilo bancário no âmbito da CPI municipal, tenha de haver **autorização judicial**.

E não há problema em diferenciar os Legislativos de nossa Federação, já que, no Brasil, vigora aquilo que a doutrina denominou **federalismo assimétrico** (cf. *item 7.3.2.3*), ocupando o Município uma posição bastante particular.

Como se sabe, apesar de ser integrante da Federação, e isso não se discute (arts. 1.º e 18, *caput*), a posição dos Municípios não se confunde com a dos Estados e a do DF.

Os Municípios **não elegem Senador** e, assim, não têm uma representação direta na Federação.

Ainda, o Município, dentro da ideia de autogoverno, **não tem Judiciário** próprio, apesar de existir, naturalmente, a prestação jurisdicional nas comarcas e seções judiciárias.

Por esse motivo, ou seja, por ter uma posição bastante particular na Federação, sustentamos que as Câmaras Legislativas de Municípios, apesar de poderem instaurar CPIs, não poderão, por ato próprio, determinar a quebra de sigilo bancário.

Mas é possível essa distinção?

Sem nenhum problema, conforme visto, também, em relação às autoridades do Fisco, à polícia e ao MP.

De acordo com o Min. Joaquim Barbosa, os **poderes instrutórios não são extensíveis às CPIs municipais**. Isso porque se trata, “... no modelo de separação de poderes da Constituição Federal, de uma excepcional derrogação

deste poder para dar a uma casa legislativa poderes jurisdicionais, posto que instrutórios. Essa transferência de poderes jurisdicionais não se pode dar no âmbito do município, exatamente porque o município não dispõe de jurisdição nem de poder jurisdicional, a transferir, na área da CPI, do Judiciário ao Legislativo” (voto na ACO 730, p. 82).

Concordamos com a conclusão, mas o nosso fundamento não é, exclusivamente, o fato de inexistir um Judiciário municipal, e sim a situação do Município na Federação, **especialmente por não ter representação no Senado Federal**.

Também não aceitando a quebra do sigilo bancário por CPI municipal, lembramos Eugênio Pacelli: “ao parlamento municipal não se deve mesmo reconhecer o poder de quebra de sigilo, exatamente em razão da posição que referidos entes (Municípios) ocupam na distribuição do Poder Público. Veja-se, por exemplo, a ampla limitação legiferante dos municípios (restrita às questões de interesse local), e, também, a inexistência de foros privativos, na Constituição da República, para os respectivos parlamentares (vereadores). Ora, sendo assim, não faria sentido permitir a eles poderes superiores às próprias prerrogativas”.²⁵

Tudo o que foi dito encontra fundamento na **ACO 730** e em parte do julgamento da **ACO 1.271** que, infelizmente, diante do encerramento da CPI, foi julgada **prejudicada**, sem a oportunidade de um melhor debate sobre a matéria e perante distinta composição. Para sabermos a posição dos atuais Ministros, teremos que aguardar o julgamento futuro sobre o tema (**matéria pendente**).

Resumindo o atual entendimento: os Municípios podem criar CPIs que, contudo, diferentemente das dos Estados e do DF, não poderão, por si, quebrar sigilo bancário.

■ 9.8.4. Comissão mista

São formadas por Deputados e Senadores para apreciar, dentre outros e em especial, os assuntos que devam ser examinados em **sessão conjunta** pelo

Congresso Nacional.

Devemos lembrar importante **comissão mista permanente** que é a **comissão mista do orçamento**, cujas finalidades estão expressas no art. 166, § 1.º, da CF/88.

■ 9.8.5. Comissão representativa

A comissão representativa apresenta a peculiaridade de constituir-se somente durante o **recesso parlamentar** (período fora da **sessão legislativa**, prevista no art. 57, *caput*).

A representatividade será do Congresso Nacional, sendo a comissão eleita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal na **última sessão legislativa ordinária do período legislativo**, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição deverá refletir, na medida do possível, a proporcionalidade da representação partidária (art. 58, § 4.º).

A redação do art. 58, § 4.º, aparece um pouco truncada, devendo ser interpretada da seguinte forma: a **sessão legislativa** é uma só e vai, na redação conferida ao art. 57, *caput*, pela EC n. 50/2006, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1.º de agosto a 22 de dezembro**. Cada sessão legislativa (**anual**) tem **dois períodos legislativos**, ou seja, um no primeiro semestre, quando será eleita a **comissão representativa** para o primeiro recesso do ano, que acontece de 18 a 31 de julho, e outro no segundo período da sessão legislativa (segundo semestre), momento em que se elegerá nova comissão representativa para o segundo recesso, que irá de 23 de dezembro a 1.º de fevereiro do ano seguinte.

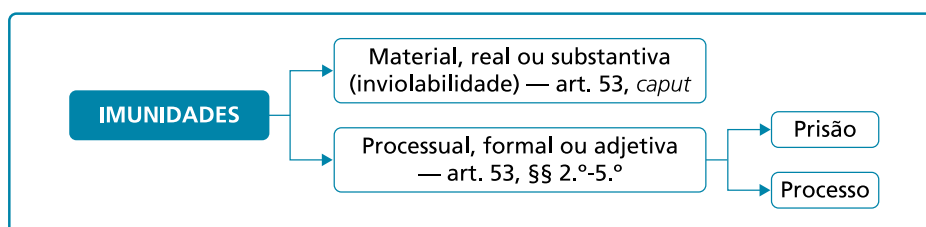
■ 9.9. IMUNIDADES PARLAMENTARES

■ 9.9.1. Aspectos introdutórios

Imunidades parlamentares são **prerrogativas** inerentes à função parlamentar,

garantidoras do exercício do mandato parlamentar, com plena liberdade.

Segundo Michel Temer, “garante-se a atividade do parlamentar para garantir a instituição. Conferem-se a deputados e senadores prerrogativas com o objetivo de lhes permitir desempenho livre, de molde a assegurar a independência do Poder que integram”.[26](#)



Referidas prerrogativas, como veremos, dividem-se em dois tipos: a) **imunidade material, real** ou **substantiva** (também denominada **inviolabilidade**), implicando a exclusão da prática de crime, bem como a inviolabilidade civil, pelas opiniões, palavras e votos dos parlamentares (art. 53, *caput*); b) **imunidade processual, formal** ou **adjetiva**, trazendo regras sobre prisão e processo criminal dos parlamentares (art. 53, §§ 2.º a 5.º, da CF/88).

Assim, importante notar que, em sua essência, as aludidas prerrogativas atribuídas aos parlamentares, em virtude da função que exercem, tradicionalmente previstas em nossas Constituições, com algumas exceções nos movimentos autoritários, reforçam a democracia, uma vez que os parlamentares podem livremente expressar suas opiniões, palavras e votos, bem como estar garantidos contra prisões arbitrárias, ou mesmo rivalidades políticas.

As regras sobre imunidades parlamentares sofreram importantes alterações com o advento da **EC n. 35, de 20.12.2001** (SF, PEC n. 2-A/1995 e CD PEC n. 610/98, com parecer favorável da CCJ n. 1.461, de 12.12.2001, Rel. Sen. José Fogaça), e passam a ser analisadas notadamente em relação ao processo criminal.[27](#)

■ 9.9.2. Imunidade parlamentar federal

Nesse tópico, após a introdução e pequena sistematização do assunto,

concentraremos a apresentação em relação às imunidades dos parlamentares federais, quais sejam, dos **Deputados Federais** e dos **Senadores da República**, de acordo com as regras fixadas na **EC n. 35/2001**, que alterou a redação do art. 53 da CF/88.

■ 9.9.2.1. *Imunidade material ou inviolabilidade parlamentar (art. 53, "caput")*

Prevista no art. 53, *caput*, tal imunidade garante que os parlamentares federais são invioláveis, **civil** e **penalmente**, por quaisquer de suas **opiniões**, **palavras** e **votos**, desde que proferidos em razão de suas funções parlamentares, no exercício e relacionados ao mandato, não se restringindo ao âmbito do Congresso Nacional. Assim, mesmo que um parlamentar esteja fora do Congresso Nacional, mas exercendo sua função parlamentar federal, em qualquer lugar do território nacional estará resguardado, não praticando qualquer crime por sua opinião, palavra ou voto.^{[28](#)}

Segundo o STF, “... a inviolabilidade alcança toda manifestação do congressista onde se possa identificar um laço de implicação recíproca entre o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a qualidade de mandatário político do agente” (RE 210.917, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.08.1998, *DJ* de 18.06.2001; AI 493.632-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13.11.2007, *DJE* de 14.03.2008).

Aqui, pedimos vênias para reproduzir interessante compilação doutrinária realizada por Alexandre de Moraes, no que tange à natureza jurídica da inviolabilidade parlamentar. Diz o autor: “dessa forma Pontes de Miranda (*Comentários à Constituição de 1967*), Nélson Hungria (*Comentários ao Código Penal*) e José Afonso da Silva (*Curso de direito constitucional positivo*) entendem-na como uma *causa excludente de crime*; Basileu Garcia (*Instituições de direito penal*), como *causa que se opõe à formação do crime*; Damásio de Jesus (*Questões criminais*), *causa funcional de isenção de pena*; ^{[29](#)} Aníbal Bruno (*Direito penal*), *causa pessoal e funcional de isenção de*

pena; Heleno Cláudio Fragoso (*Lições de direito penal*), *causa de irresponsabilidade*; José Frederico Marques (*Tratado de direito penal*), *causa de incapacidade penal por razões políticas*”. [30](#)

Não importa, pois, qual a denominação que se dê; o importante é saber que a imunidade material (inviolabilidade) **impede que o parlamentar seja condenado**, já que há ampla descaracterização do tipo penal, **irresponsabilizando-o penal, civil, política e administrativamente (disciplinarmente)**. Trata-se de **irresponsabilidade geral**, desde que, é claro, tenha ocorrido o fato em razão do exercício do mandato e da função parlamentar. [31](#)

A **imunidade material**, mantida pela **EC n. 35/2001**, é sinônimo de **democracia**, representando a garantia de o parlamentar não ser perseguido ou prejudicado em razão de sua atividade na tribuna, na medida em que assegura a independência nas manifestações de pensamento e no voto. Em contraposição, a garantia da **imunidade processual**, antes da alteração trazida pela **EC n. 35/2001**, vinha sendo desvirtuada, aproximando-se mais da noção de **impunidade** que de prerrogativa parlamentar, o que motivou a sua alteração, conforme será visto.

■ 9.9.2.2. *Imunidade formal ou processual*

A imunidade formal ou processual está relacionada à **prisão** dos parlamentares, bem como ao **processo** a ser instaurado contra eles. Devemos, então, saber quando os parlamentares poderão ser presos, bem como se será possível instaurar processo contra eles.

■ 9.9.2.2.1. *Imunidade formal ou processual para a prisão (art. 53, § 2.º). Perspectivas em razão do julgamento da AP 470 — “mensalão”*

Os parlamentares passam a ter imunidade formal para a prisão a partir do momento que são **diplomados** pela Justiça Eleitoral, portanto, antes de

tomarem **posse** (que seria o ato público e oficial mediante o qual o Senador ou Deputado se investiria no mandato parlamentar). A **diplomação** nada mais é que um atestado garantindo a regular eleição do candidato. Ocorre antes da posse, configurando o **termo inicial** para a atribuição da **imunidade formal para a prisão**.³²

Nesse sentido, expresso é o art. 53, § 2.º, da CF/88, na redação determinada pela **EC n. 35/2001**: “desde a **expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional não poderão ser **presos**, salvo em **flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”.

Isso posto, passamos a esquematizar melhor as regras sobre a **prisão dos parlamentares federais**, que poderá ser **processual** (art. 53, § 2.º), também chamada de **cautelar**, ou somente em razão de **sentença judicial definitiva transitada em julgado**.

Deixando claro, não se caracterizando a hipótese de prisão processual ou cautelar, a **única** forma de prisão do parlamentar será em razão de **sentença penal transitada em julgado e contra a qual não caibam mais recursos**; nesse caso, sob pena de se violar o **princípio da presunção de inocência** (art. 5.º, LVII, da CF/88), segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o **trânsito em julgado** de **sentença penal condenatória**”.

Em relação à primeira, uma dúvida surge: a **prisão processual**, por sua vez, violaria o **princípio da presunção de inocência**?

Também **não**. Muito embora se reconheça o caráter excepcional da prisão processual, a Constituição, em seu art. 5.º, LXI, expressamente a admite, ao estabelecer que “ninguém será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária** competente, salvo nos casos de *transgressão militar* ou *crime propriamente militar*, definidos em lei”, bem como, ao prescrever, na *vigência do estado de defesa*, a possibilidade de decretação da prisão por crime contra o Estado pelo *executor da medida*, que deverá comunicá-la imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for

legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial (art. 136, § 3.º, I).

A) PRISÃO PROCESSUAL DOS PARLAMENTARES FEDERAIS

De acordo com a doutrina, a **prisão processual** divide-se em três: a) prisão em flagrante; b) prisão preventiva; c) prisão temporária.

Os parlamentares federais só poderão ser **cautelamente** presos e colocados no cárcere na hipótese de **flagrante de crime inafiançável**.

Estamos diante daquilo que o Min. Celso de Mello denominou “estado de relativa incoercibilidade pessoal dos congressistas (*freedom from arrest*), que só poderão sofrer prisão provisória ou cautelar numa **única e singular hipótese**: situação de flagrância em crime inafiançável” (Inq. 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.02.1991, Plenário).

Nessa hipótese, de acordo com o art. 53, § 2.º, os autos deverão ser remetidos à Casa Parlamentar respectiva no prazo de **24 horas**, para que, pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros (*quorum* qualificado, cf. *Inf. STF* 28/96), **resolva sobre a prisão**.

Convém destacar que a votação dos congressistas não mais será secreta, conforme regra anterior à EC n. 35/2001, e sim pelo **voto aberto**, implementando-se, por meio dessa nova sistemática, a transparência que deve sempre imperar nesse tipo de votação.

A aprovação pela Casa, dessa forma, é **condição necessária** para a manutenção da prisão em flagrante delito de crime inafiançável (prisão processual ou cautelar) já realizada.

Portanto, se a Casa parlamentar decidir pela não manutenção do cárcere, a prisão deverá ser imediatamente “relaxada” (trata-se de decisão política e discricionária do Parlamento, que poderá assim resolver mesmo na hipótese de não se verificar qualquer ilegalidade, o que nos permite afirmar que a regra do art. 53, § 2.º, deve ser tida como especial em relação à regra geral do art. 5.º, LXV, da CF/88, que exige o requisito da ilegalidade para o relaxamento da prisão). [33](#)

Por outro lado, se a Casa mantiver a prisão em flagrante, entendemos que os

autos deverão ser encaminhados, também no prazo de **24 horas** (art. 306, § 1.º, do CPP), ao **STF** (no caso de parlamentares federais — art. 53, § 1.º, c/c o art. 102, I, “b”, da CF/88), para que, então, sejam cumpridas as regras do **art. 310 do CPP**³⁴ (na redação dada pela **nova lei de prisões** — Lei n. 12.403/2011), relaxando a prisão ilegal ou convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva ou, ainda, concedendo, sempre de modo fundamentado, a liberdade provisória, com ou sem fiança.

B) PRISÃO DE PARLAMENTAR EM RAZÃO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO

Finalmente, temos de tratar da prisão em caso de **sentença judicial transitada em julgado**,³⁵ tema que ganhou repercussão com o julgamento do “mensalão” (**AP 470**) e que deve ser analisado juntamente com a regra contida no **art. 55, § 2.º**, da CF/88, que cuida da perda do mandato.

Em um primeiro momento, em relação à **perda do mandato**,³⁶ por 5 x 4, no julgamento da **AP 470** (mensalão), em **17.12.2012**, o STF entendeu ser **automática** em razão da condenação criminal transitada em julgado (“... todos os condenados por **mais de 4 anos de reclusão** ou cuja condenação diga respeito a **ato de improbidade administrativa** — o que ocorre nos **crimes contra a administração pública**, tais como **peculato** e **corrupção passiva**, deve implicar **automaticamente a perda dos mandatos eletivos**” — *Notícias STF*, 17.12.2012), aplicando-se a regra do art. 15, III, e afastando-se a incidência do art. 55, § 2.º.³⁷

CUIDADO: em **08.08.2013**, mudando esse entendimento, agora por **6 x 4**, no julgamento da **AP 565** (não votou o Min. Fux, impedido, em razão de ter apreciado o caso concreto quando era Min. do STJ), com a participação no julgamento de 2 novos Ministros que não haviam votado no caso do “mensalão” (Min. Barroso e Min. Teori Zavascki), o STF passou a estabelecer que a **perda do mandato de parlamentar condenado não é automática**, devendo ser observada a regra do **art. 55, § 2.º**, CF/88.

Por sua vez, no tocante à **prisão em razão da sentença judicial transitada em julgado** (ou seja, quando não mais couberem recursos), o Tribunal entendeu

que as penas impostas poderão ser executadas imediatamente.

Em **13.11.2013**, também analisando a AP 470, o STF admitiu a **decretação parcial de trânsito em julgado**, nas partes do acórdão que não mais admitissem recurso, considerando os seus capítulos autonomamente. Dessa forma, resolvendo questão de ordem, a Corte:

- **decretou**, por unanimidade, “**o trânsito em julgado e determinar a executoriedade imediata dos capítulos autônomos do acórdão condenatório**, não impugnados por embargos infringentes, considerados os estritos limites do recurso”;

- por maioria, **excluiu** “da execução imediata do acórdão as condenações já impugnadas por meio de embargos infringentes, considerados os estritos limites de cada recurso, por ainda pender o respectivo exame de admissibilidade”;

- por maioria, **admitiu** “o trânsito em julgado e a execução imediata da pena em relação aos réus cujos segundos embargos declaratórios já teriam sido julgados nesta sessão. No tocante ao trânsito em julgado parcial do acórdão, à luz dos capítulos autônomos nele existentes, prevaleceu o voto do Ministro Joaquim Barbosa”;

- por consequência, **certificou** o trânsito em julgado, conforme o caso, independentemente de publicação do acórdão;

- **determinou** fossem lançados os nomes dos réus no rol dos culpados, bem como “expedidos mandados de prisão, para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime inicial legalmente correspondente ao *quantum* da pena transitada em julgado, nos termos do art. 33, § 2.º, do CP” (*Inf. n. 728/STF*).

Por todo o exposto, as regras sobre a prisão dos parlamentares federais podem ser assim resumidas:

- **regra geral antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória**: os parlamentares federais **não** poderão ser presos, seja a **prisão penal processual** (também denominada prisão **provisória** ou **cautelar**, englobando aí a prisão temporária, em flagrante delito de crime

afiançável e a preventiva), [38](#) seja a **prisão civil** (art. 5.º, LXVII); [39](#)

■ **única exceção à regra geral:** a única hipótese em que será permitida a prisão do parlamentar federal, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e desde a expedição do diploma, será em caso de **flagrante de crime inafiançável**; [40](#)

■ **flagrante de crime inafiançável:** mesmo nessa hipótese, de acordo com o art. 53, § 2.º, os autos deverão ser remetidos à Casa Parlamentar respectiva (por exemplo, sendo Deputado Federal, para a Câmara dos Deputados), no **prazo de 24 horas**, para que, pela **maioria absoluta de seus membros** (*quorum* qualificado, cf. *Inf. STF 28/96*) e pelo **voto aberto, decida sobre a prisão**;

■ **prisão em caso de sentença judicial transitada em julgado (STF):** evoluindo a decisão proferida no julgamento do “mensalão”, **AP 470** (decisões em 17 e 21.12.2012), pela qual se reconhecia a perda automática do mandato (art. 15, III), o STF, em momento seguinte (**08.08.2013**), no julgamento da **AP 565**, passou a estabelecer que a **perda do mandato de parlamentar condenado não é automática**, devendo ser observada a regra do **art. 55, § 2.º**, CF/88 (cf. *item 9.11.4*).

■ **9.9.2.2.2. Imunidade formal ou processual para o processo (art. 53, §§ 3.º a 5.º)**

As regras sobre a **imunidade formal** para o **processo criminal** dos parlamentares sofreram profundas alterações pela **EC n. 35/2001**, mitigando a amplitude dessa “garantia”.

Antes da aludida reforma, os parlamentares não podiam ser processados sem a prévia licença da Casa, que, em muitos casos, não era deferida, ocasionando situações de verdadeira **impunidade**.

Conforme ponderou o Senador José Fogaça, relator do *Parecer n. 1.461/2001*, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do SF, “a alteração do instituto da imunidade parlamentar é passo imprescindível para a recuperação do prestígio do Poder Legislativo” (*DSF* de 13.12.2001, p. 30789-

30790).

De acordo com a nova regra, então, oferecida a denúncia, o Ministro do STF poderá recebê-la **sem a prévia licença da Casa Parlamentar**. Assim, como já era permitido, poderão ser instaurados inquéritos policiais e processos de natureza civil, disciplinar ou administrativa, além do oferecimento da denúncia criminal. A novidade, como visto, reside no fato de que, oferecida a denúncia, poderá ela ser recebida no STF **sem a prévia licença da Casa respectiva**.

Pois bem, após o recebimento da denúncia contra o Senador ou Deputado, **por crime ocorrido após a diplomação**, o STF dará ciência à Casa respectiva, que, por **iniciativa de partido político** nela representado e pelo voto da **maioria absoluta** (*quorum* qualificado) de seus membros, poderá, até a decisão final, **sustar o andamento da ação**.

O **pedido de sustação** será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa Diretora, sendo que a sustação do processo **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato (cf. art. 53, §§ 3.º e 5.º).

Afinal de contas, o pedido de sustação poderá implementar-se até a **decisão final da ação penal movida contra o parlamentar** (art. 53, § 3.º), ou **no prazo improrrogável de 45 dias contados do seu recebimento pela Mesa Diretora** (art. 53, § 4.º)? As duas disposições devem ser harmonizadas, ou seja, a Casa respectiva tem até o final da ação penal para decidir, pelo *quorum* da **maioria absoluta** de seus membros, se suspende ou não a aludida ação penal. O pedido de sustação, pelo partido político, na respectiva Casa representado, poderá implementar-se logo após a ciência dada pelo STF ou em período subsequente, não havendo prazo certo para tanto, já que, como visto, a **Casa** terá até o trânsito em julgado da sentença final proferida na ação penal para sustá-la. Apesar de não haver prazo certo, contudo, o período durante o qual a ação tramita (até o seu trânsito em julgado) deverá ser respeitado. O único prazo fixado é o de **45 dias** contado do recebimento, pela Mesa Diretora, do pedido de sustação efetuado pelo partido político. Esse prazo, sim, de 45 dias, é **improrrogável**.⁴¹

Assim, de acordo com a nova regra trazida pela **EC n. 35/2001**:

■ **não há mais necessidade de prévio pedido de licença para se processar parlamentar federal no STF**, podendo, no máximo, a Casa legislativa, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, **sustar o andamento da ação penal de crime ocorrido após a diplomação**. Isso significa dizer que ainda há imunidade para o processo criminal contra o parlamentar, só que de maneira mitigada, já que, para o seu implemento, ela dependerá de ação da Casa, e não de sua inação, como se verificava antes. Conforme argumentou José Fogaça, “... não se elimina a possibilidade de o parlamento sustar um processo criminal contra um de seus membros quando verificar que esse está carregado de um viés exclusivamente político, mas não se permite a impunidade pelo simples fato de não haver decisão” (*DSF* de 13.12.2001, p. 30789-30790);

■ **não há mais imunidade processual em relação a crimes praticados antes da diplomação**. Diferentemente das regras fixadas para crimes praticados após a diplomação, pela nova sistemática não haverá necessidade de o STF dar ciência à respectiva Casa de ação penal de crime praticado **antes da diplomação**. Nessas hipóteses, por conseguinte, **não poderá**, também, a respectiva Casa, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, **sustar o andamento da aludida ação**.[42](#)

Por fim, imagine-se a situação de ter havido sustação do processo em crime praticado **após a diplomação**, em concurso de agentes por parlamentar e outro indivíduo que não goze da referida imunidade. Nesses casos, o **STF**, por motivo de conveniência, decidiu pelo **desmembramento do processo** (art. 80 do CPP), em razão da diferença do regime de prescrição, visto estar suspenso somente o prazo prescricional em relação ao parlamentar (cf. STF, Inq. 1.107/MA, Rel. Min. Octavio Gallotti).

■ 9.9.2.3. *Prerrogativa de foro (“foro privilegiado”) (art. 53, § 1.º)*

■ **9.9.2.3.1. Regra geral para os parlamentares federais — STF. Cessado o mandato parlamentar, por regra (salvo exceção comentada nos itens seguintes), deixa de existir competência originária da Corte para o julgamento de ação penal contra membro do Congresso Nacional**

De acordo com o art. 53, § 1.º, os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o **STF**, pela prática de **qualquer tipo de crime**, seja de natureza penal comum *stricto sensu*, seja crimes contra a vida, eleitorais, contravenções penais (art. 53, § 1.º, c./c. art. 102, I, “b” — infrações penais comuns).

Estamos diante do tópico sobre a **competência por prerrogativa de função**, que será mais bem desenvolvido em processo penal. Não podemos deixar de sistematizar, contudo, alguns aspectos que podem ser perguntados nas provas de Direito Constitucional, apesar de envolverem o art. 84 do CPP. Vamos a algumas situações:

■ **infração cometida durante o exercício da função parlamentar:** a competência, como visto, será do **STF**, não havendo necessidade de pedir autorização à Casa respectiva para a instauração do processo (recebimento da denúncia); basta ser dada ciência ao Legislativo, que poderá sustar o andamento da ação. Mas pensemos em outra situação: praticado o crime durante o exercício do mandato, instaurado o processo mas não findo ou, ainda, tendo sido sustado o andamento da ação. Encerrado o mandato, continuará o julgamento no STF? Ocorrerá o fenômeno da *perpetuatio jurisdictionis*? Até **25.08.1999** prevalecia o entendimento no STF exposto na orientação dada pela Súmula 394, ou seja, mesmo que cessasse o mandato, a competência especial por prerrogativa de função **permanecia com o STF**. No julgamento da questão de ordem no Inq. 687-SP, o STF **cancelou a Súmula 394**, entendendo que a competência deixa de ser do STF, pois não existe mais o exercício da função.^{[43](#)}

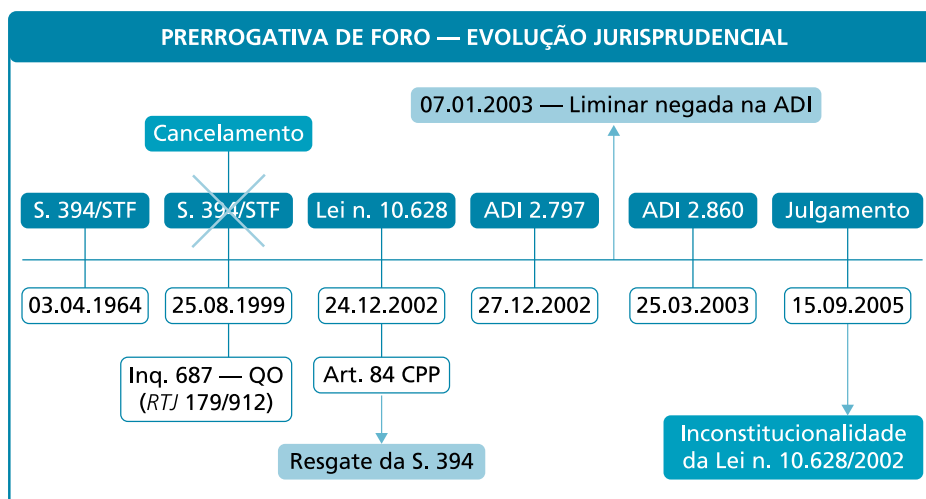
Às pressas, inusitadamente, foi publicada a **Lei n. 10.628, de 24.12.2002**, que, ao dar nova redação ao art. 84 do CPP, “ressuscitou” a já banida e execrada regra da *perpetuatio jurisdictionis* após o término do mandato das

autoridades. Em nosso entender, a nova regra, retrógrada, ao manter o foro privilegiado para os crimes praticados durante o mandato, é flagrantemente inconstitucional, já que veiculada por lei ordinária e não por emenda constitucional, ferindo, desta feita, o princípio da separação de Poderes.

Em razão da aludida lei, foram propostas a **ADI 2.797**, ajuizada em 27.12.2002 pela *Associação Nacional dos Membros do MP (CONAMP)*, e que teve seu pedido de liminar negado pelo STF (07.01.2003), e a **ADI 2.860**, proposta pela *Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)*, distribuída por prevenção, em 25.03.2003, àquela primeira ajuizada pela CONAMP.

Por maioria de votos (7 x 3), em 15.09.2005, o Plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade do foro especial para ex-ocupantes de cargos públicos e/ou mandatos eletivos (*Inf. 401/STF*).

Posteriormente, em 17.05.2012, os **embargos declaratórios** opostos pelo Procurador-Geral da República na ADI 2.797 foram **acolhidos**, por maioria, pelo Plenário, para assentar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1.º e 2.º do art. 84 do CPP, inseridos pelo art. 1.º da Lei n. 10.628/2002, terão **eficácia a partir de 15.09.2005**. “Na espécie, alegava-se que a norma declarada inconstitucional teria vigido por 3 anos — com alterações nas regras de competência especial por prerrogativa de função quanto às ações de improbidade,⁴⁴ inquéritos e ações penais — a exigir fossem **modulados** os efeitos do julgado. Destacou-se a necessidade de se preservar a validade dos atos processuais praticados no curso das mencionadas ações e inquéritos contra ex-ocupantes de cargos públicos e de mandatos eletivos julgados no período de **24.12.2002**, data de vigência da Lei n. 10.628/2002, até a data da declaração de sua inconstitucionalidade, **15.09.2005** (*vide* quadro abaixo). Pontuou-se que inúmeras ações foram julgadas com fundamento na Lei n. 10.628/2002 e, por segurança jurídica, necessário adotar-se a **modulação**, assegurada a eficácia *ex nunc*, nos termos do **art. 27 da Lei n. 9.868/99**. Asseverou-se que os **processos ainda em tramitação não teriam sua competência deslocada para esta Corte**” (*Inf. 666/STF* — grifamos).



Convém anotar, contudo, que, mesmo se introduzido por emenda constitucional, em nosso entender, o pretendido “privilégio” violaria o princípio da isonomia, na medida em que se estariam tratando *desigualmente* pessoas *iguais*, quais sejam, **ex**-ocupantes de cargo ou função pública e cidadãos comuns.

■ **delito cometido antes do exercício parlamentar:** nessa hipótese, diplomando-se o réu (em caso de ser eleito, por exemplo, Deputado Federal), o processo deve ser remetido imediatamente ao STF, que, entendendo preenchidos os requisitos, dará prosseguimento à ação penal. Nesse caso, como se trata de crime praticado **antes da diplomação**, pela nova regra não há mais imunidade processual. Assim, a ação criminal deverá ser processada no próprio STF (tendo em vista a regra de competência prevista de forma genérica no art. 53, § 1.º), sem qualquer interferência do Legislativo, não havendo, sequer, necessidade de ser dada ciência à Casa respectiva. **Findo o mandato, caso o processo não tenha terminado, encerrar-se-á a competência do STF, devendo o processo retornar para o juiz natural** (por exemplo, dependendo da competência, o Juízo do Foro Criminal Mário Guimarães, na Capital de São Paulo);

■ **delito cometido após o encerramento do mandato:** mesmo que o réu já tenha sido um dia parlamentar, não poderá alegar tal fato, não havendo, portanto, nessa situação, competência por prerrogativa de função, conforme a **S. 451/STF**: “a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do

exercício funcional” — Sessão Plenária de 1.º.10.1964, *DJ* de 08.10.1964.

■ **9.9.2.3.2. Renúncia ao mandato. Caso “Gulliver”. “Ciranda dos processos”. “Valsa processual”. Perspectivas de resgate da S. 394/STF (AP 333)**

Neste item, propomos a análise da seguinte questão: o ato de **renúncia** de parlamentar constitui gesto legítimo para afastar a prerrogativa de foro?

Para tanto, lembramos o polêmico caso decorrente da **renúncia** do ex-Deputado Federal R. C. L. (PSDB-PB), que, nos autos da **AP 333**, estava sendo acusado do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra o ex-Governador da Paraíba, Tarcísio Burity, por ter, consoante narra a denúncia, efetuado disparos de arma de fogo em um restaurante de João Pessoa (de nome “Gulliver” e, por isso, ter ficado conhecido o caso por este nome).

De acordo com o relatório da referida ação penal, ao tempo dos fatos, o denunciado (R. C. L.) era Governador do Estado da Paraíba. Por esse motivo, a denúncia foi oferecida perante o STJ (art. 105, I, “a”).

R. C. L., nas eleições de 1994, elege-se Senador da República, e nas duas eleições que se seguiram, Deputado Federal, sendo que o seu último mandato terminaria em 31.12.2010.

Assim, sendo ele **parlamentar federal**, nos termos do art. 53, § 1.º, já estudado, expedido o diploma, a competência para julgar R. C. L. passou a ser do **STF** (muito embora ao tempo dos fatos — 05.11.1993 — fosse Governador da Paraíba).

Durante a ação penal (tendo sido a denúncia recebida em 2002), houve amplo direito de defesa, e se tentou ouvir uma testemunha por mais de 1 ano.

Em 31.10.2007, faltando 5 dias para o início do julgamento, já marcado pelo STF, R. C. L. renunciou ao mandato de Deputado Federal (legislatura 2007-2010).

A polêmica se instaurara. Não sendo mais Deputado Federal, ou seja, passando a ser uma pessoa comum, o STF deixava de ser competente, segundo

a orientação firmada a partir do cancelamento da S. 394 e, também, ao se declarar inconstitucional a Lei n. 10.628/2002?

O tema se mostrou bastante complicado, tanto é que a votação estava empatada em 4 x 4. Parte dos ministros entendia que a renúncia caracterizava “evidente propósito de frustrar o julgamento pelo STF”, verdadeiro “**abuso de direito**”, e outros 4 achavam que a renúncia tinha sido legítima.

Ao final, em 05.12.2007, por 7 x 4, os Ministros entenderam que a competência do Supremo cessava ao ter R. C. L. deixado de ser Deputado Federal, mesmo na hipótese de renúncia. Como afirmou Celso de Mello, invocando o princípio do **juiz natural**, a renúncia é inquestionável. “Foi recebida e gerou efeitos, antes do julgamento final do processo em curso, sendo um desses efeitos a cessação da competência do STF para julgá-lo” (*Notícias STF*, 05.12.2007).

Por esse motivo, passando a ser pessoa comum, sem prerrogativa de foro, os autos foram remetidos para o **Juízo Criminal da Comarca de João Pessoa**.

Dada a importância do tema, pedimos vênias para transcrever a ementa do referido acórdão, que deixa claro, também, o afastamento da competência do júri quando o acusado tem prerrogativa de foro:

“EMENTA: Ação penal. Questões de ordem. Crime doloso contra a vida imputado a parlamentar federal. Competência do STF *versus* competência do tribunal do júri. **Norma constitucional especial**. Prevalência. Renúncia ao mandato. Abuso de direito. Não reconhecimento. Extinção da competência do STF para julgamento. Remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. 1. O réu, na qualidade de detentor do mandato de parlamentar federal, detém prerrogativa de foro perante o STF, onde deve ser julgado pela imputação da prática de crime doloso contra a vida. 2. A norma contida no art. 5.º, XXXVIII, da CR, que garante a instituição do júri, cede diante do disposto no art. 102, I, ‘b’, da Lei Maior, definidor da competência do STF, dada a especialidade deste último. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da Corte. 3. **A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a declinação da competência do STF para o juízo criminal de primeiro grau**. Ausente o abuso de direito

que os votos vencidos vislumbraram no ato. 4. Autos encaminhados ao juízo atualmente competente” (**AP 333**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 05.12.2007, *DJE* de 11.04.2008).

Como se verifica, os autos iniciaram a sua tramitação no STJ (Governador de Estado), tendo sido remetidos para o STF (SF e CD) e, agora, para a Justiça Comum. Essa situação, bastante criticada, foi denominada pelo Ministro Gilmar Mendes “**ciranda dos processos**”, levando-o inclusive a repensar um eventual e futuro resgate da atualmente cancelada S. 394 do STF (cf. *Notícias STF*, 1.º.07.2008 — *íntegra da entrevista coletiva*). Em outra oportunidade, o Min. Joaquim Barbosa denominou esse “vai e volta” de “**valsa processual**”.

■ 9.9.2.3.3. **Renúncia ao mandato. Manutenção da competência do STF. Abuso de direito. Fraude processual inaceitável (AP 396)**

O tema da prerrogativa de foro veio a ser reanalisado pelo STF em outro caso polêmico: a **AP 396**, julgada em **28.10.2010**.

De acordo com as *informações públicas contidas no site do STF*, apurava-se suposto esquema a caracterizar os crimes de **formação de quadrilha** e **peculato**, envolvendo, dentre outros, o ex-Deputado Federal N. D. (PMDB-RO) (*Inf. 606/STF* e *Notícias STF*, 28.10.2010).

No caso em análise, o *MP do Estado de Rondônia* instaurou “... procedimento investigatório a partir de representações em que se questionava a licitude de contrato publicitário firmado entre a Assembleia Legislativa local e determinada empresa. No decorrer das apurações, o *parquet* constatara a existência de suposto esquema criminoso — engendrado para desviar dinheiro daquela Casa Legislativa — no qual o réu, na qualidade de diretor financeiro da Assembleia Legislativa, teria assinado vários cheques e os repassado, por mais de 2 anos, à mencionada empresa de publicidade a pretexto de pagamento pelos serviços, sequer prestados. Em razão disso, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público daquela unidade federativa oferecera denúncia contra o parlamentar e outros 7 corréus por formação de quadrilha e peculato, em

concurso material e de pessoas. Após o recebimento da inicial acusatória pela Corte de origem, o réu fora empossado Deputado Federal e o processo, **desmembrado, remetido ao STF**, que assim o mantivera e afirmara a validade dos atos judiciais praticados anteriormente à diplomação e à posse do parlamentar federal” (*Inf. 606/STF*).

Muito embora a decisão proferida no caso do “mensalão” no sentido de julgamento de todos os corréus em um mesmo processo (**Inq. 2.245**), a regra que o STF vem adotando é, havendo prerrogativa de foro de um dos envolvidos, o **desmembramento** do processo, com base na **conveniência da instrução** e na **racionalização dos trabalhos**.

No caso em referência, a denúncia foi oferecida em **24.06.1999** pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, porque ainda não havia a prerrogativa de foro. Contudo, em **03.01.2005**, N. D. tomou posse como Deputado Federal, para exercício do mandato na *Legislatura 2003-2007*, quando, então, por esse motivo, o juiz da 3.^a Vara Criminal da Comarca de Porto Velho (RO) determinou o **desmembramento** dos autos, com a **remessa** do processo para o **STF**, em razão da prerrogativa de foro.

A ação foi distribuída, no STF, em **16.08.2005** e, às vésperas do julgamento — **27.10.2010** —, o Deputado Federal **renunciou** ao mandato, sendo que o crime prescreveria no dia **04.11.2010**.

Eis o cronograma dos fatos:

- **24.06.1999** — oferecimento de denúncia na comarca de Porto Velho;
- **03.01.2005** — posse como Deputado Federal;
- **16.08.2005** — a ação é distribuída no STF;
- **22.10.2010** — inclusão do feito em pauta é publicada no *DJE*;
- **27.10.2010** — o Deputado Federal renuncia ao mandato;
- **28.10.2010** — o STF resolve questão de ordem e reconhece a subsistência da competência da Corte mesmo diante da hipótese de renúncia ao mandato;
- **04.11.2010** — haveria a prescrição do crime.

Revedo o julgamento proferido no caso do ex-Deputado Federal R. C. L. (AP 333), no qual o STF, por 7 x 4, entendia que a renúncia (no caso, faltando 5 dias para o julgamento) era válida e, assim, cessaria a competência do STF, por **8 x 1**, modificando o seu entendimento, **decidiu**, em 28.10.2010, **julgar a ação (AP 396)**, mantendo a sua competência, mesmo não sendo mais o réu parlamentar, e condenando-o à pena de reclusão de 13 anos, 4 meses e 10 dias, em regime inicialmente fechado, além de 66 dias-multa, pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288, CP) e peculato (art. 312, CP).

Temos, assim, um **novo entendimento do STF**, que, a nosso ver, mostra-se **muito acertado**.

Dentre os vários argumentos expendidos pelos Ministros para se manter a competência do STF, a renúncia, às vésperas do julgamento, caracterizou-se como **“fraude processual inaceitável”**, frustrando a atuação jurisdicional do Estado e tornando, assim, o STF **refém** da opção do réu. Sustentou-se, ainda, tratar-se a atitude de verdadeiro **abuso de direito**. “A Constituição garante a imunidade, mas não a impunidade.” A fraude à lei mostra-se, ainda, “eticamente pouco sustentável”, não podendo o STF aceitar a “... manipulação de instâncias para efeito de prescrição”, citando-se, por fim, a afirmação de Ulpiano, segundo a qual “não se pode tirar proveito da própria torpeza”. [45](#)

■ **9.9.2.3.4. Necessidade de definição de critério objetivo para a caracterização da hipótese de fraude processual e abuso de direito a manter a competência do STF em caso de renúncia ao mandato. Renúncia abusiva. Renúncia manipulativa. Debate (AP 536)**

O tema sobre a manutenção da competência do STF em caso de renúncia ao mandato de parlamentar federal foi retomado no julgamento da **AP 536** (27.03.2014, *DJE* de 12.08.2014).

De acordo com os autos, “o ex-parlamentar e outros réus foram denunciados pelo Procurador-Geral da República pela suposta prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, em concurso material e em concurso de pessoas. Houve o desmembramento do processo no Supremo e a AP 536 passou a tramitar

apenas contra E. A., por ele ser deputado federal à época. A denúncia foi recebida pelo Supremo no dia 3 de dezembro de 2009. Posteriormente, o réu foi interrogado e as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. Em 7 de fevereiro em 2014, o Procurador-Geral da República apresentou alegações finais e, reiterando os termos da denúncia, pediu a aplicação de uma pena de 22 anos de prisão. No dia 19 de fevereiro de 2014, o réu comunicou ao Supremo que havia renunciado ao mandato de deputado” (*Notícias do STF* de 27.03.2014).

Nesse caso concreto, o STF entendeu não ter havido fraude processual e abuso de direito e, assim, determinou, depois de mais de 9 anos de tramitação do feito, a sua **remessa** para o juízo de primeiro grau.

Diferentemente do entendimento firmado na AP 396, houve o afastamento do risco de prescrição da pena em abstrato e não se reconheceu, como dissemos, a caracterização de abuso de direito.

Propôs, então, o Min. Roberto Barroso, Relator, a definição de um critério geral mais objetivo para o reconhecimento da fraude em casos futuros. **Infelizmente, no referido julgado, não houve maioria absoluta para a definição do marco temporal, deixando a Corte essa fixação para um outro momento.**

Diante da importância do tema, gostaríamos de esquematizar, para reflexão, as propostas lançadas pelos Ministros para o reconhecimento da manutenção da competência do Tribunal, mesmo no caso de renúncia parlamentar. Vejamos as sugestões de **marcos temporais** a manter a competência do STF, definição essa, aliás, que entendemos fundamental para que não se tenha incerteza de como deve ser a regra processual, especialmente em matéria penal. Assim, se a renúncia se der em momento posterior aos indicados abaixo, o STF continuaria competente para julgar a ex-autoridade:

- **Ministro Roberto Barroso:** recebimento da denúncia, aplicando-se, analogicamente, o art. 55, § 4.º, CF/88;
- **Ministro Teori Zavascki:** endossou a proposta de Barroso;
- **Ministro Luiz Fux:** endossou a proposta de Barroso;

- **Ministro Joaquim Barbosa:** endossou a proposta de Barroso;
- **Ministra Rosa Weber:** encerramento da instrução processual (art. 11 da Lei n. 8.038/90);
- **Ministro Dias Toffoli:** lançamento, pelo relator da ação penal, do **visto** com a liberação do processo ao revisor;
- **Ministro Celso de Mello:** não entendeu conveniente a definição de marco temporal, devendo a análise se dar caso a caso;
- **Ministro Gilmar Mendes:** não entendeu conveniente a definição de marco temporal, devendo a análise se dar caso a caso;
- **Ministro Marco Aurélio:** não entendeu conveniente a definição de marco temporal, devendo a análise se dar caso a caso;
- **Ministro Ricardo Lewandowski:** ausente justificadamente;
- **Ministra Cármen Lúcia:** ausente justificadamente.

■ **9.9.2.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento**

As prerrogativas de foro são definidas pela Constituição em relação às autoridades no exercício efetivo da função. Assim, de acordo com o entendimento fixado pela Corte, por exemplo e conforme visto, um ex-parlamentar não teria mais a referida prerrogativa com o término do seu mandato ou nas citadas hipóteses de fraude.

Contudo, em razão de **circunstâncias especiais** a serem apreciadas, demonstradas e justificadas em cada caso concreto, lembrando que, nos termos do art. 78, III, do CPP, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação, poder-se-á deliberar no sentido do julgamento conjunto de todos os corréus (cf. *Inf. 673/STF*).

Esse entendimento, negando o desmembramento, foi o que se verificou no julgamento do “mensalão” (**Inq. 2.245** e correspondente **AP 470**), no qual, dos 38 réus, apenas 3 eram parlamentares, e, diante dessa circunstância, decidiu a

Corte, em razão da prerrogativa, no sentido da competência do STF para o julgamento de **todos**⁴⁶ os réus. Vejamos:

“Questão de ordem. Inquérito. Desmembramento. Art. 80 do CPP. Critério subjetivo afastado. Critério objetivo. **Inadequação ao caso concreto**. Manutenção integral do inquérito sob julgamento da Corte. Rejeitada a proposta de adoção do critério subjetivo para o desmembramento do inquérito, nos termos do art. 80 do CPP, resta o critério objetivo, que, por sua vez, é **desprovido de utilidade no caso concreto**, em face da **complexidade do feito**. Inquérito não desmembrado. Questão de ordem resolvida no sentido da **permanência**, sob a jurisdição do **STF**, de **todas** as pessoas denunciadas” (**Inq 2.245-QO-QO**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.12.2006, Plenário, *DJ* de 09.11.2007, e entendimento mantido na solução de questão de ordem que se colocou na correspondente **AP 470**, em 02.08.2012 — cf. outros detalhes do tema no *item 10.4.15.4*).

Devemos deixar claro, contudo, que o **desmembramento** é a **regra**. Somente em situações **excepcionalíssimas** é que deve haver o julgamento conjunto no Tribunal com jurisdição de maior graduação. (Remetemos o nosso ilustre leitor para o *item 10.4.15.4*, no qual desenvolvemos a matéria e trazemos importante tentativa de *roteirização* proposta pelo Min. Roberto Barroso no julgamento do **Inq 3.515 AgR/SP**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.02.2014, Plenário, *DJE* de 25.02.2014.)

■ 9.9.2.5. Outras garantias

■ **sigilo de fonte**: de acordo com o art. 53, § 6.º, e conforme já estabelecido antes do advento da **EC n. 35/2001**, “os Deputados e Senadores não serão obrigados a **testemunhar** sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações”;

■ **incorporação às forças armadas de Deputados e Senadores**: “a incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, **dependerá de prévia licença**

da Casa respectiva” (art. 53, § 7.º, mantida a referida garantia na **EC n. 35/2001**);

■ **imunidades durante a vigência de estado de sítio e de defesa:** como regra geral, durante a vigência desses estados de anormalidade, os parlamentares não perdem as imunidades. Apenas durante o **estado de sítio** as imunidades poderão ser **suspensas**, mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida (art. 53, § 8.º, regra essa mantida pela **EC n. 35/2001**).

■ **9.9.2.6. As imunidades parlamentares podem ser renunciadas?**

Imaginem vocês, candidatos que se preparam para concursos públicos, que, em determinado momento, o examinador formule as seguintes questões:

■ José da Silva, deputado federal, no exercício do mandato, portanto, após a diplomação, comete um crime. Recebida a denúncia no STF, após ser dada ciência ao Parlamento há **sustação do andamento da ação**. O deputado, inconformado com a acusação, faz questão de ser processado, para provar a sua inocência. Que deverá fazer? Como as imunidades parlamentares dizem respeito ao cargo que ocupa e não à pessoa, a única maneira que o parlamentar encontrará para provar a sua inocência será esperar o término do mandato, ou renunciar de imediato, para que perca, então, a imunidade;

■ José da Silva, deputado federal, na tribuna, em empolgante discurso, declara que o governo federal desviou verba do erário público, de forma irregular. Em meio à empolgação, diz ter dados seguros e, inclusive, diz renunciar às suas imunidades para provar que fala a verdade. Isso é possível? Não, na medida em que as imunidades são irrenunciáveis. Caso fale isso, podemos encarar como mera demagogia política!

Portanto, devemos observar, mais uma vez, que as **imunidades parlamentares são irrenunciáveis** por decorrerem da função exercida, e não da figura do parlamentar.

Assinalou Celso de Mello que “o instituto da imunidade parlamentar atua, no contexto normativo delineado por nossa Constituição, como condição e garantia de **independência do Poder Legislativo**, seu real destinatário, em face dos outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora **não** constitua uma prerrogativa de ordem subjetiva deste. Trata-se de **prerrogativa de caráter institucional**, inerente ao Poder Legislativo, que só é conferida ao parlamentar ‘*ratione muneris*’, em função do cargo e do mandato que exerce. É por essa razão que **não se reconhece ao congressista**, em tema de imunidade parlamentar, **a faculdade de a ela renunciar**. Trata-se de garantia institucional deferida ao Congresso Nacional. **O congressista, isoladamente considerado, não tem, sobre ela, qualquer poder de disposição**” (*Inq. 510/DF*, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.02.1991, Plenário, *RTJ* 135/509).

■ 9.9.2.7. As imunidades parlamentares estendem-se aos suplentes?

As imunidades parlamentares são prerrogativas que decorrem do efetivo exercício da função parlamentar. Não são garantias da pessoa, mas prerrogativas do cargo. Assim, as imunidades, inclusive o foro privilegiado, **não** se estendem aos suplentes, a não ser que assumam o cargo ou estejam em seu efetivo exercício:

“Suplente de Senador. Interinidade. Competência do STF para o julgamento de ações penais. Inaplicabilidade dos arts. 53, § 1.º, e 102, I, ‘b’, da Constituição Federal. Retorno do titular ao exercício do cargo. Baixa dos autos. Possibilidade. (...) Os membros do Congresso Nacional, pela condição peculiar de representantes do povo ou dos Estados que ostentam, atraem a competência jurisdicional do STF. O foro especial possui natureza *intuitu functionae*, ligando-se ao cargo de Senador ou Deputado e não à pessoa do parlamentar. Não se cuida de prerrogativa *intuitu personae*, vinculando-se ao cargo, ainda que ocupado interinamente, razão pela qual se admite a sua perda ante o retorno do titular ao exercício daquele. A diplomação do suplente não lhe estende automaticamente o regime político-jurídico dos congressistas, por constituir mera formalidade anterior e essencial a possibilitar a posse

interina ou definitiva no cargo na hipótese de licença do titular ou vacância permanente” (Inq. 2.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.05.2007, *DJ* de 29.06.2007). Nesse sentido, cf., ainda, Inq. 2.421-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, j. 14.02.2008, *DJE* de 04.04.2008. No mesmo sentido: **Inq. 2.800**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 23.06.2010, *DJE* de 19.08.2010 (*Inf. 595/STF* — transcrição).

■ 9.9.3. Parlamentares estaduais

Aos **Deputados Estaduais** (cf. art. 27, § 1.º) serão aplicadas as mesmas regras previstas na Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, **imunidades**, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Quando dizemos “mesmas regras”, observar a correspondência, ou seja, ao falar em prisão, somente no caso de flagrante delito de crime inafiançável, devendo os autos ser remetidos à **Assembleia Legislativa** dentro de 24 horas para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ao falar em competência por prerrogativa de função, de acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo, entenda-se a do **Tribunal de Justiça**. Ao falar em prática de crime comum **após a diplomação**, o TJ poderá instaurar o processo sem a prévia licença da Assembleia Legislativa, mas deverá a ela dar ciência, sendo que, pelo voto da maioria de seus membros, o Poder Legislativo Estadual poderá sustar o andamento da ação. Por fim, entenda-se plenamente assegurada a **imunidade material** dos Deputados Estaduais, que são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Da mesma forma como ocorre com os parlamentares federais, não há mais (após a **EC n. 35/2001**) imunidade formal para crimes praticados **antes da diplomação**.

■ 9.9.4. Parlamentares municipais

De acordo com o art. 29, VIII, como já visto, os Municípios reger-se-ão por lei orgânica, que deverá obedecer, dentre outras regras, à da **inviolabilidade**

dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Ou seja, o Vereador Municipal somente terá **imunidade material** (excluindo-se a responsabilidade penal e a civil), desde que o ato tenha sido praticado *in officio* ou *propter officium* e na **circunscrição municipal**, não lhe tendo sido atribuída a imunidade formal ou processual. Nesse sentido, precisas são as palavras do Min. Celso de Mello:

“EMENTA: 1. A garantia constitucional da **imunidade parlamentar em sentido material** (CF, art. 29, VIII, c/c o art. 53, *caput*) **exclui a responsabilidade penal** (e também **civil**) do membro do Poder Legislativo (Vereadores, Deputados e Senadores), por manifestações, orais ou escritas, desde que **motivadas pelo desempenho do mandato (prática in officio)** ou **externadas em razão deste (prática propter officium)**. Tratando-se de Vereador, a inviolabilidade constitucional que o ampara no exercício da atividade legislativa estende-se às opiniões, palavras e votos por ele proferidos, **mesmo fora do recinto da própria Câmara Municipal**, desde que **nos estritos limites territoriais do Município a que se acha funcionalmente vinculado**. Precedentes. AI 631.276/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). 3. Essa prerrogativa político-jurídica — que protege o parlamentar (como os Vereadores, p. ex.) em tema de responsabilidade penal — incide, de maneira ampla, nos casos em que as declarações contumeliosas tenham sido proferidas no recinto da Casa legislativa, notadamente da tribuna parlamentar, hipótese em que será absoluta a inviolabilidade constitucional. Doutrina. Precedentes” (AI 818.693, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 1.º.08.2011, DJE de 03.08.2011. No mesmo sentido, cf. HC 74.201, j. 12.11.1996).

Além disso, nos termos do art. 29, IX, a lei orgânica também deverá observar as proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto na CF para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa.

■ 9.10. INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS DOS PARLAMENTARES

FEDERAIS

Em decorrência de sua nobre função, aos parlamentares é vedado o exercício de algumas atividades, bem como determinados comportamentos, desde a **expedição do diploma** e, posteriormente, após tomarem **posse**. Os Deputados e Senadores **não poderão**, enuncia o art. 54, I e II, da CF/88:

I — DESDE A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA	■ firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; ■ aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior.
II — DESDE A POSSE	■ ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; ■ ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, “a”; ■ patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, “a”; ■ ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

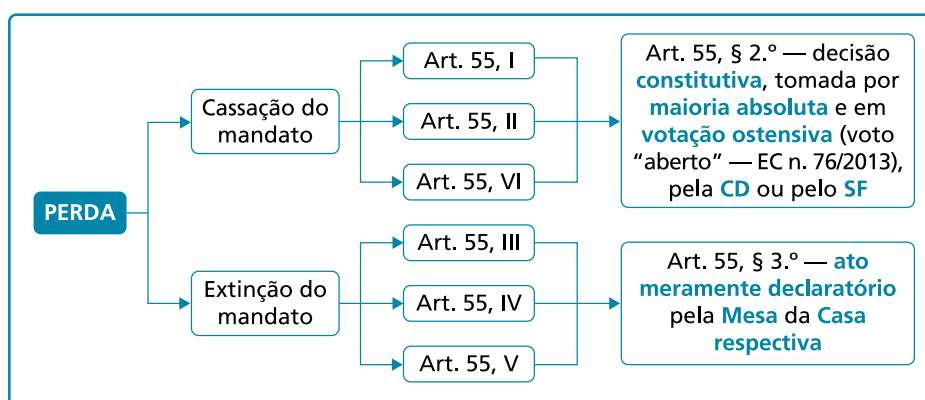
■ 9.11. PERDA DO MANDATO DO DEPUTADO OU SENADOR

■ 9.11.1. Hipóteses de perda do mandato e suas peculiaridades

O art. 55 da CF/88 estabelece que perderá o mandato o parlamentar federal:

HIPÓTESES DE PERDADO MANDATO (ART. 55)	PECULIARIDADES
I — quando o parlamentar infringir qualquer das proibições estabelecidas no art. 54 (quadro anterior);	§ 2.º a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal , por maioria absoluta , mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
II — cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ;	§ 1.º É incompatível com o decoro parlamentar , além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Nesta hipótese, de acordo com o § 2.º do art. 55, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal , por maioria absoluta , mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
III — que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;	§ 3.º a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva , de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
IV — que perder ou tiver suspensos os direitos políticos (Obs.:	

sabemos ser, na vigência da CF/88, vedada a cassação de direitos políticos. Porém, o art. 15 da CF/88 estabelece hipóteses de perda e suspensão);	§ 3.º a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
V — quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;	§ 3.º a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
VI — que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.	§ 2.º a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.



■ 9.11.2. Cassação **47** x extinção do mandato

Pela regra fixada no art. 55, § 2.º, da CF/88, na hipótese de **cassação do mandato**, a sua perda será **decidida** pela **Câmara dos Deputados** ou pelo **Senado Federal**, por **maioria absoluta**, mediante provocação da respectiva

Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Em se tratando de **extinção**, por outro lado (art. 55, § 3.º), a perda será **declarada** pela **Mesa da Casa respectiva**, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

Dessa forma, na primeira situação (cassação — **decisão** — pela Casa), o provimento político terá natureza **constitutiva**. Na segunda (extinção — **declaração** — pela Mesa), a natureza será **declaratória**.

Cassação do mandato, ensina José Afonso da Silva,⁴⁸ “é a **decretação** da **perda** do mandato por ter seu titular incorrido em falta funcional definida em lei e punida com esta sanção”. **Extinção do mandato**, por seu turno, define-se como “o **perecimento** do mandato pela ocorrência de fato ou ato que torna automaticamente **inexistente a investidura eletiva**, tal como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões expressamente fixado (desinteresse, que a Constituição eleva à condição de renúncia), perda ou suspensão dos direitos políticos”. Nesse caso, trata-se de provimento meramente **declaratório**, pois a Mesa apenas reconhece (por declaração) a ocorrência do fato ou ato do **perecimento do mandato**.⁴⁹

■ 9.11.3. Votação aberta na hipótese de cassação do mandato: aprovação da “PEC do voto aberto” (EC n. 76/2013). Avanço democrático

Conforme visto, nas hipóteses de **cassação do mandato** (art. 55, I, II e VI), de acordo com a Constituição, a perda do mandato será **decidida** pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, nos termos do art. 55, § 2.º.

Aperfeiçoando a regra estabelecida pelo constituinte originário, a *EC n. 76/2013* **aboliu a votação secreta** nos casos de perda de mandato de Deputado ou de Senador. Dessa forma, a votação deverá ser **ostensiva**, ou seja, **aberta**, para que o povo saiba como os seus representantes votaram em relação a situações extremamente graves como a condenação criminal de parlamentar.

■ **9.11.4. A perda do mandato parlamentar em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado e a interpretação fixada pelo STF no julgamento da AP 470 (“mensalão”), bem como da AP 565 (art. 15, III, x art. 55, §§ 2.º e 3.º). O caso concreto da AP 396** [50](#)

Conforme já anunciamos anteriormente, em um primeiro momento o STF entendeu que, na hipótese de condenação de **réus parlamentares** pela prática, entre outros, de **crimes contra a Administração Pública**, tendo em vista tratar-se de conduta juridicamente incompatível com os deveres inerentes ao cargo, impunha-se “a perda do mandato como medida adequada, necessária e proporcional” (**AP 470**, j. 17.12.2013). [51](#)

Evoluindo, contudo, a Corte mudou o entendimento e passou a reconhecer a especialidade do art. 55, § 2.º, no sentido de a perda do cargo depender de decisão da Casa (**AP 565**, j. 08.08.2013).

A) AP 470 — “mensalão” — 17.12.2012

O tema precisava ser esclarecido pela Suprema Corte, que o fez, em um primeiro momento, em julgamento apertado, por **5 x 4**, ao decidir que os três Deputados Federais condenados **na AP 470** (“mensalão”) e que ainda exerciam o mandato, quais sejam, João Paulo Cunha (PT/SP), Pedro Henry (PP/MT) e Valdemar Costa Neto (PR/SP), perderiam, **automaticamente**, os seus mandatos com o **trânsito em julgado** da **sentença penal condenatória**.

A decisão, muito embora tenha sido proferida pela maioria exigida, deu-se sem estar completo o Plenário da Corte.

O Min. Teori Albino Zavascki, apesar de já ter tomado posse em **29.11.2012**, em razão da vaga deixada pelo Ministro Cezar Peluso, aposentado em setembro ao completar 70 anos, não participou do referido julgamento.

Ainda, no momento da decisão (17.12.2012), encontrava-se também em aberto a vaga do Min. Ayres Britto, aposentado compulsoriamente desde 17.11.2012, nos termos do Decreto Presidencial de 14.11.2012, e que veio a ser preenchida somente com a indicação e posse do Min. Luís Roberto Barroso em 26.06.2013.

Portanto, 9 Ministros, naquele momento, resolveram a questão. Estando empatado em 4 x 4 (no sentido ou não da perda automática do mandato, em razão da sentença penal condenatória transitada em julgado), o Min. Celso de Mello, em 17.12.2012, proferiu o voto de desempate, determinando a aplicação do art. 55, § 3.º, da CF/88, que apenas atribui ao Parlamento o poder de **declarar** a perda do mandato, e não o de **decidir** sobre a sua concretização, afastando-se, assim, a regra contida no art. 55, § 2.º.

De acordo com a sua decisão, “... todos os condenados por **mais de 4 anos de reclusão** ou cuja condenação diga respeito a **ato de improbidade administrativa** — o que ocorre nos crimes contra a administração pública, tais como peculato e corrupção passiva, deve implicar **automaticamente a perda dos mandatos eletivos**. E, neste caso, a perda deve ocorrer, no entender do ministro Celso de Mello, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, como no crime de peculato, punido com penas que vão de 2 a 12 anos de reclusão. Já quanto aos demais casos, isto é, em condenações por tempo inferior e por delitos de menor potencial ofensivo, caberá à Câmara, no entendimento do ministro Celso de Mello, deliberar sobre a perda ou não do mandato, conforme previsto no parágrafo 2.º do artigo 55 da Constituição Federal” (*Notícias STF*, 17.12.2012).

Cabe observar que, além desses argumentos trazidos pelo Min. Celso de Mello, o STF estabeleceu que, uma vez **transitado em julgado o processo** (*Inf. 693/STF*):

- por unanimidade, ficam **suspensos os direitos políticos de todos os réus condenados**, com base no **art. 15, III**, da CF;
- por maioria, fica **decretada a perda de mandato eletivo** dos Deputados Federais acusados na ação penal;
- as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos previstas no art. 15 da CF são taxativas;
- o Poder Legislativo pode decretar a perda de mandato de Deputado Federal ou Senador, com fundamento em perda ou suspensão de direitos políticos, bem assim em condenação criminal transitada em julgado (CF,

art. 55, IV e VI). Essa previsão constitucional, contudo, **vincula-se aos casos em que a sentença condenatória não decretar a perda de mandato**, em razão de não estarem presentes os requisitos legais (CP, art. 92, I, “a” e “b”, e parágrafo único),⁵² ou por ter sido proferida anteriormente à expedição do diploma, com o trânsito em julgado ocorrente em momento posterior;

■ não se aplica o art. 55 da CF (juízo político), uma vez que a **perda de mandato eletivo** caracteriza-se como **efeito irreversível da sentença condenatória**;

■ de acordo com o art. 55, § 3.º, introduzido pela EC n. 35/2001, estabeleceu-se a possibilidade de **suspensão do processo**, com o objetivo de se evitar que o parlamentar seja submetido a perseguição política. Na medida em que essa situação não se verificou, o feito poderia seguir o seu trâmite regular;

■ os réus cometeram **crimes contra a Administração Pública** quando no exercício do cargo, a revelar conduta **incompatível** com o exercício de mandato eletivo.

Ressalte-se que esse **primeiro entendimento** sobre a perda automática do mandato não refletia a jurisprudência do STF que, de modo instável (lembrando que o placar foi fixado por **5 x 4**), modificou-se sem a composição completa da Corte.

Isso porque, conforme se observa pelos precedentes indicados abaixo, o STF **entendia** ser a regra do **art. 55, § 2.º**, da CF/88 **especial** sobre a regra geral do art. 15, III (nesse sentido, preciso o voto do Min. Dias Toffoli, apesar de vencido, nesse primeiro momento, proferido no julgamento do “mensalão”):

■ **MS 21.443/DF** (j. 22.04.1992): não obstante a decisão tenha analisado uma situação concreta de falta de decoro parlamentar (art. 55, II), assim definiu o Min. Paulo Brossard: “observadas as formalidades constitucionalmente enunciadas, a decisão, da Câmara ou do Senado, poderá ser discutível, poderá ser injusta, poderá ser desacertada, mas será definitiva e irrecorrível; será insuscetível de revisão judicial. Porque a Constituição deu à Câmara e só à Câmara, ao Senado e só ao Senado, a

competência para decidir algo que à Câmara e ao Senado diz respeito”.

■ **RE 179.502** (j. 31.05.1995): apesar de ser a questão diferente, na linha do voto do Min. Relator Moreira Alves, pelo princípio da especialidade, a regra do art. 55, VI e § 2.º, deveria prevalecer sobre a regra geral do art. 15, III (*lex speciali derogat lex generali*). Nesse sentido, bastante elucidativo o voto do Min. Celso de Mello.

Esse entendimento, que então **prevalecia** no STF, superado naquele primeiro momento da análise da AP 470, parecia seguir a *ratio* da regra prevista pela *Assembleia Nacional Constituinte* que acolheu, por 407 votos (16 contrários e 6 abstenções, de um total de 429), a **Emenda n. 1.895 — Modificativa** do texto do “Centrão” (de autoria do Constituinte **Antero de Barros**, destacada pelo Constituinte Fernando Lyra), para fixar, com precisão, a regra especial do art. 55, §§ 2.º e 3.º, sendo que, no caso, como explicou o Constituinte Nelson Jobim, teria o objetivo de, em relação à condenação criminal (embora estivessem preocupados, na discussão, com os **crimes de menor potencial ofensivo**, reconheça-se), entregar a decisão, que seria política, ao Plenário das Casas respectivas, não sendo a perda do mandato automática. [53](#)

O STF, contudo, de modo explícito, definiu **posicionamento**, estabelecendo interpretação harmonizadora dos dispositivos em antinomia (arts. 15, III, e 55, VI, § 2.º) a partir do substrato axiológico de normas constitucionais (**ética e moralidade na administração pública, isonomia e princípio republicano**).

B) AP 565 — mudança de entendimento — aplicação da regra do art. 55, § 2.º — a perda do mandato depende de deliberação da Casa — 08.08.2013

CUIDADO: em momento seguinte, como se apontou, no julgamento da **AP 565**, em **08.08.2013**, agora com os votos do Min. Teori Zavascki e do Min. Luís Roberto Barroso, por 6 x 4 (o Min. Fux não votou porque se declarou impedido, pois já havia julgado o caso concreto quando era Ministro do STJ), o STF decidiu **que a perda do mandato parlamentar não é automática e depende de manifestação da Casa**, declarando a regra do art. 55, § 2.º, especial em relação à geral contida no art. 15, III.

Ainda, ficou estabelecido que a perda do mandato a ser decidida pela Casa não impediria o réu parlamentar de cumprir a pena imposta. Assim, a Corte, reconhecendo o não cabimento de qualquer outro recurso, certificou o trânsito em julgado, determinou fosse lançado o nome dos réus no rol dos culpados e expediu os competentes mandados de prisão.

C) AP 396 e a “PEC do voto aberto”

Pois bem, diante desse novo posicionamento, qual seja, o de que a perda do mandato não é automática, em outro caso, envolvendo a condenação de Deputado Federal à pena de mais de 13 anos de reclusão, em regime fechado, por formação de quadrilha e peculato (AP 396, N. D.), diante da *Representação n. 20/2013*, levou-se à Câmara dos Deputados a discussão sobre a perda do mandato parlamentar.

Em 28.08.2013, a Casa manteve o mandato do deputado federal que cumpria pena. Isso mesmo, estávamos diante da estranha situação de se ter um deputado federal mantido no cargo e cumprindo pena em regime fechado. [54](#)

Essa situação gerou a revolta da sociedade e, sem dúvida, serviu para a mobilização do Congresso Nacional.

Procurando “escutar a voz das ruas”, o Parlamento passou a analisar duas propostas de emenda: a) “PEC do voto aberto” (pois, naquele momento, a votação ainda era secreta); b) PEC que estabelece a perda imediata do mandato de parlamentar condenado por crimes contra a Administração Pública.

A primeira foi aprovada e promulgada como EC n. 76/2013. A segunda, até o fechamento desta edição, ainda estava sendo discutida no Parlamento (*matéria pendente*).

Em 12.02.2014, em nova votação e à luz da regra introduzida pela EC n. 76/2013, a Câmara dos Deputados cassou, por 467 votos favoráveis e 1 abstenção, o mandato do Deputado Federal N. D., assumindo, assim, de modo definitivo o seu suplente.

A sociedade presenciou a histórica primeira votação aberta na Câmara dos Deputados, “corrigindo” o dito “erro político” cometido na primeira votação (pelo voto fechado) que o manteve no cargo (*Agência Câmara Notícias*).

Esse novo julgamento teve por objeto a **Rep. 22/2013**, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e que apontou dois motivos para a **quebra do decoro** (art. 55, II — portanto, outro fundamento): a) ter o deputado votado no processo de perda do seu próprio mandato, violando o regimento interno (art. 180, § 6.º); b) ter saído, nas dependências externas da Câmara, “algemado e transportado de camburão do serviço penitenciário para o Presídio da Papuda, em Brasília”, o que afetaria a imagem da Casa.

■ 9.11.5. É possível a renúncia do cargo por parlamentar submetido a processo que vise ou possa levá-lo à perda do mandato?

Sim, é possível a **renúncia de parlamentar** submetido a processo que vise ou possa levá-lo à perda do mandato. **Todavia**, nessa hipótese, a EC de Revisão n. 6/94, constitucionalizando o previsto no art. 1.º e seu parágrafo único do Decreto Legislativo n. 16, de 24.03.1994 (art. 55, § 4.º, da CF/88), veio disciplinar que a aludida renúncia **terá seus efeitos suspensos** até as deliberações finais descritas nos §§ 2.º e 3.º do art. 55. Assim, nos termos do decreto, a renúncia “... fica sujeita à **condição suspensiva**, só produzindo efeitos se a decisão final não concluir pela perda do mandato”. **No caso de ter sido a decisão final pela perda do mandato**, o parágrafo único do aludido decreto legislativo dispõe que a **declaração de renúncia será arquivada**, não produzindo efeitos no sentido de que já terá sido declarada a perda do mandato.

■ 9.12. HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ A PERDA DO MANDATO DO DEPUTADO OU SENADOR E OUTRAS REGRAS

O art. 56 da CF/88 enumera as hipóteses em que o Deputado ou Senador **não perderá o mandato**, quais sejam:

- **quando investido nos cargos de:** Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária (art. 56, I);

■ **quando licenciado pela respectiva casa por:** motivo de doença (art. 56, II, 1.^a parte);

■ **quando licenciado pela respectiva casa para:** tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse **120 dias** por sessão legislativa (art. 56, II, 2.^a parte).

Algumas outras regras também foram estabelecidas, concernentes a temas correlatos às regras acima expostas. Vejamo-las:

■ **nos casos de vaga, investidura em funções previstas no art. 56, I, ou licença superior a 120 dias:** haverá convocação do suplente para assumir o mandato (art. 56, § 1.^o);

■ **ocorrendo vaga, não havendo suplente e faltando mais de 15 meses para o término do mandato:** será feita nova eleição para preencher a vaga (art. 56, § 2.^o);

■ **nas hipóteses de investidura nos cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária (art. 56, I):** o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato;

■ **haverá perda das imunidades parlamentares no caso de investidura nos cargos acima apontados?** Sabemos que, por força do art. 56, I, o parlamentar federal não perderá o mandato. No entanto, **perderá (ou melhor, ficarão suspensas) as imunidades parlamentares**, de acordo, inclusive, com o art. 102, § 1.^o, do *RISTF*, que **cancelou** a Súmula 4, a qual dizia o contrário. **Assim, apesar de não perder o mandato, as imunidades parlamentares ficarão suspensas;**[55](#)

■ **e a prerrogativa de foro em matéria penal subsiste se o parlamentar estiver afastado nas hipóteses do art. 56, por exemplo, no caso de estar investido no cargo de Ministro de Estado?** Conforme visto, os parlamentares não perdem o mandato (art. 56, I), mas ficam com as imunidades suspensas. Contudo, em situação particular, ao menos em sede de cautelar, o STF entendeu estar preservada a garantia constitucional da prerrogativa de foro em matéria penal.

Essa questão foi analisada pela Corte no julgamento da medida cautelar no **MS 25.579,56** e o Min. Joaquim Barbosa, com precisão, confirmou a manutenção da prerrogativa de foro.

Tratava-se de mandado de segurança buscando trancar a tramitação e processamento de representação por quebra de decoro parlamentar de Deputado Federal licenciado e investido no cargo de Ministro de Estado.

De acordo com o voto divergente e vencedor (no julgamento do pedido de liminar), embora tenha praticado atos na condição de Ministro de Estado, não se caracterizavam como inerentes à função executiva, mas, sim, **condutas que violavam o Código de Ética parlamentar**, preservando-se, portanto, a prerrogativa de foro no tocante à matéria penal.

■ 9.13. PROCESSO LEGISLATIVO

■ 9.13.1. Considerações introdutórias

O processo legislativo consiste nas regras procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos “atores” envolvidos no processo. [57](#)

Nesse sentido é que o art. 59 da CF/88 estabelece que o processo legislativo envolverá a elaboração das seguintes espécies normativas:

- emendas à Constituição;
- leis complementares;
- leis ordinárias;
- leis delegadas;
- medidas provisórias;
- decretos legislativos;
- resoluções.

Regulamentando o parágrafo único do art. 59 da CF/88, a **LC n. 95/98**, alterada pela **LC n. 107/2001**, dispôs sobre as técnicas de elaboração, redação, alteração das leis, bem como sua consolidação, e de outros atos normativos.

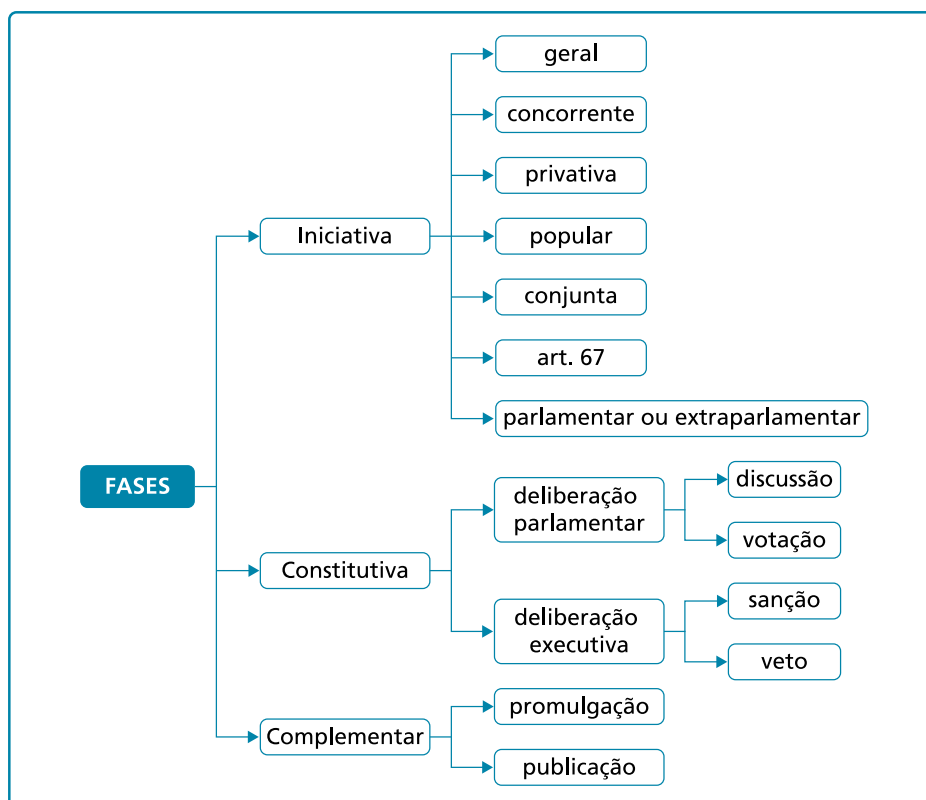
A importância fundamental de estudarmos o processo legislativo de formação das espécies normativas é sabermos o correto trâmite a ser observado, sob pena de ser inconstitucional a futura espécie normativa.

Quando estudamos as regras sobre **controle de constitucionalidade**, apontamos que uma espécie normativa poderia apresentar um vício formal (subjetivo ou objetivo) ou um vício material; vícios esses caracterizadores da inconstitucionalidade. O **vício formal**, como apontado, diz respeito ao processo de formação da lei (processo legislativo), cuja mácula pode estar tanto na fase de iniciativa (vício formal subjetivo) como nas demais fases do processo de formação da lei (vício formal objetivo, por exemplo, desrespeito ao *quorum* de votação). Já o **vício material** refere-se ao conteúdo da espécie normativa, à matéria por ela tratada.

Em decorrência de todos esses detalhes é que se estabelece um *controle prévio* ou *preventivo*, realizado não só pelo Legislativo (Comissões de Constituição e Justiça) como, também, pelo Executivo (por meio do veto), sem falar, é claro, do *controle repressivo*, ou *posterior*, cujo objeto é a lei ou ato normativo (já constituídos), sendo realizado pelo sistema difuso ou concentrado (lembrar que o controle de constitucionalidade no Brasil é **jurisdicional misto**).

Para descrever o processo legislativo e suas diversas etapas, didaticamente, começaremos pelo processo de **elaboração das leis ordinárias**, por ser o mais complexo de todos, juntamente com o processo de **elaboração das leis complementares**, cujas diferenças, como veremos, são poucas. Posteriormente, quando estivermos tratando das demais espécies normativas, apontaremos as peculiaridades que as individualizam.

■ 9.13.2. Esquema do processo legislativo das leis ordinárias e complementares



■ 9.13.3. Fase de iniciativa

A primeira fase do processo legislativo é a **fase de iniciativa**, *deflagradora, iniciadora, instauradora* de um procedimento que deverá culminar, desde que preenchidos todos os requisitos e seguidos todos os trâmites, com a formação da espécie normativa.

Buscando critérios classificatórios, dividimos as hipóteses de iniciativa em: **geral, concorrente, privativa, popular, conjunta, do art. 67 e a parlamentar ou extraparlamentar**.

■ 9.13.3.1. Regra geral para a iniciativa

De maneira ampla, a CF atribui competência às seguintes pessoas e aos órgãos, conforme prevê o art. 61, *caput* (**iniciativa geral**):

- qualquer Deputado Federal ou Senador da República;
- Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do

Congresso nacional;

- Presidente da República;
- Supremo Tribunal Federal;
- Tribunais Superiores;
- Procurador-Geral da República;
- cidadãos.

■ 9.13.3.2. *Iniciativa concorrente*

A **iniciativa concorrente** refere-se à competência atribuída pela Constituição a mais de uma pessoa ou órgão para deflagrar o processo legislativo. Como exemplo podemos lembrar a iniciativa para elaborar leis complementares e ordinárias, concedida a qualquer **membro ou Comissão da Câmara, Senado ou Congresso**, ao **Presidente da República** e aos **cidadãos**.

Outro exemplo de iniciativa concorrente a ser lembrado, e que será estudado oportunamente, diz respeito à alteração da Constituição por meio de emendas constitucionais (cf. art. 60, I, II e III).

■ 9.13.3.3. *Iniciativa “privativa” (reservada ou exclusiva)*

Algumas leis são de **iniciativa privativa** de determinadas pessoas ou órgãos, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por eles, sob pena de se configurar **vício formal de iniciativa**, caracterizador da inconstitucionalidade do referido ato normativo.

Muito embora a Constituição fale em competência privativa, melhor seria dizer, em muitas das hipóteses, **competência exclusiva** (ou **reservada**), em razão da marca de sua **indelegabilidade**, como se percebe a seguir.

■ 9.13.3.3.1. *Iniciativa reservada ao Presidente da República*

Como exemplo, temos o art. 61, § 1.º, que estabelece como **leis de iniciativa privativa do Presidente da República** as que:

■ **fixem ou modifiquem:** os efetivos das Forças Armadas; [58](#)

■ **disponham sobre:** *a)* criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; *b)* organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; *c)* servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; [59](#) *d)* organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; [60](#) *e)* criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública, observado o disposto no art. 84, VI (nova redação determinada pela **EC n. 32, de 11.09.2001**); *f)* militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. [61](#)

■ **9.13.3.3.2. Iniciativa reservada aos Governadores dos Estados e do DF e aos Prefeitos — simetria com o modelo federal**

As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do Presidente da República, pelos **princípios da simetria** e da **separação de Poderes**, devem ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas matérias terão de ser iniciadas pelos Chefes do Executivo (Governadores dos Estados e do DF e Prefeitos), sob pena de se configurar **inconstitucionalidade formal subjetiva**. Nesse sentido:

“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal, entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal” (ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 25.08.2004, *DJ* de 1.º.10.2004).

“À luz do princípio da simetria, é (*sic*) de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis que disciplinem o regime jurídico dos militares (art. 61, § 1.º, II, ‘f’, da CF/1988). Matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar” (ADI 2.966, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2005, *DJ* de 06.05.2005).

Assim, está **errado** dizer que o Presidente da República terá iniciativa privativa (mais tecnicamente reservada) para dispor sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou no aumento de sua remuneração, em todas as unidades da Federação. A sua atribuição, conforme visto, restringe-se ao **âmbito federal** (art. 61, § 1.º, II, “a”) sendo, em cada unidade federativa, a iniciativa do **respectivo** Chefe do Poder Executivo.

Essa dúvida deixa de existir em relação às outras hipóteses do art. 61, § 1.º, II, na medida em que nas alíneas “b” e “c” já há indicação expressa da União e dos Territórios (que, aliás, são uma extensão da União, não podendo ser definidos como unidade federativa).

■ 9.13.3.3. *Iniciativa reservada do Judiciário*

A CF/88, no **art. 96, II**, dispõe serem de iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) do STF, Tribunais Superiores e Tribunais de Justiça as matérias de seu interesse exclusivo.

Além disso, há previsão no **art. 93** para a elaboração de lei complementar, de iniciativa do STF, que disporá sobre o **Estatuto da Magistratura**.

Em relação ao tema, destacamos a **EC n. 73/2013**, que criou os Tribunais Regionais Federais das 6.^a, 7.^a, 8.^a e 9.^a Regiões, introduzindo o § 11 ao art. 27 do ADCT.

A necessidade de se aumentar por emenda decorre da regra contida no art. 27, § 6.º, do ADCT, que criou, em 1988, os atuais 5 TRFs.

Contra referida emenda, foi ajuizada a **ADI 5.017** pela *Associação Nacional dos Procuradores Federais (ANPAF)* e, em **18.07.2013**, o Min. Joaquim

Barbosa concedeu liminar, **suspendendo os seus efeitos** (*pendente de apreciação pelo Pleno*).

Dentre os argumentos expostos, está o **suposto vício formal por violação ao art. 96, II, “c” e “d”**, reconhecido em sede de liminar e com fundamento em alguns precedentes, como ADI 3.930, ADI 2.966 etc. (esses precedentes tratam de matérias de iniciativa de lei reservada ao Governador do Estado e que foram objeto de PEC estadual).

Contudo, com o máximo respeito, não nos parece haver relação entre a jurisprudência pacífica do STF em aplicar a simetria aos projetos de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §§ 1.º e 2.º), com o tema objeto da ADI 5.017, qual seja, a alteração da Constituição por emenda para criação de tribunais inferiores.

Nesse sentido, destacamos a EC 45/2004, que criou o CNJ (apesar de não ser tribunal inferior é órgão do Poder Judiciário — art. 92, I-A), bem como extinguiu os tribunais de alçada. Ainda, a EC 24/99 pôs fim aos juízes classistas. Todas, nesses pontos, foram declaradas constitucionais pelo STF.

O constituinte originário fixou os legitimados para reforma da Constituição, indicados no art. 60, I, II e III, e os limites materiais nas cláusulas pétreas, não se podendo criar mais um limite a partir do art. 96, II. Resta aguardar a decisão da Corte, lembrando a importância da criação desses novos TRFs para eficiência da Justiça Federal no Brasil.

■ 9.13.3.3.4. *Iniciativa reservada aos Tribunais de Contas*

O **art. 73** da CF/88 estabelece que o **TCU** exerce, no que couber, as atribuições previstas no **art. 96**.

Nos termos do art. 96, portanto, compete ao TCU propor ao Poder Legislativo (**iniciativa reservada**) projetos de lei referentes às matérias ali indicadas, por exemplo, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros.

Esse entendimento deve ser estendido, também, às demais Cortes de Contas,

e, nesse caso, o projeto de lei tem de ser encaminhado pelo respectivo Tribunal, sob pena de vício formal (art. 75, *caput*, da CF/88).

“EMENTA: Inconstitucionalidade formal da lei estadual, de origem parlamentar, que altera e revoga diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A Lei estadual 2.351/2010 dispôs sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas estadual. Conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam as Cortes de Contas do país das **prerrogativas** da **autonomia** e do **autogoverno**, o que inclui, essencialmente, a **iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento**, como resulta da interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96, II, ‘d’, da CF...” (ADI 4.418-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.10.2010, Plenário, DJE de 22.02.2011 e, no mesmo sentido ADI 1.994, j. 24.05.2006).

■ 9.13.3.3.5. *Assuntos exclusivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal*

O art. 51, IV, estatui ser competência privativa (exclusiva) da Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a **iniciativa de lei** para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros previstos na lei de diretrizes orçamentárias.

Idêntica é a previsão constante do art. 52, XIII, em relação ao Senado Federal.

■ 9.13.3.3.6. *Podemos falar em iniciativa reservada de matéria tributária?*

Não.

O art. 61, § 1.º, II, “b”, da CF/88 determina serem de iniciativa reservada do Presidente da República as leis que disponham sobre “organização administrativa e judiciária, **matéria tributária** e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos **Territórios**”.

Assim, o STF já entendeu que a exclusividade para iniciar o processo legislativo sobre matéria tributária refere-se às leis dos **Territórios Federais**.

No âmbito da União, Estados-Membros, DF e Municípios, a iniciativa de leis sobre **matéria tributária** é **concorrente** entre os Chefes do Executivo e os membros do Legislativo, podendo-se, ainda, avançar e sustentar a iniciativa popular sobre matéria tributária, desde que observadas as formalidades do art. 61, § 2.º.

Nessa linha: “a Constituição de 1988 admite a **iniciativa parlamentar** na instauração do processo legislativo em tema de **direito tributário**. A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado” (ADI 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.05.1992, *DJ* de 27.04.2001).

Ou, ainda: “(...). Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1.º, II, “b”, da Constituição, que diz respeito **exclusivamente aos Territórios Federais**” (*grifamos* — ADI 3.205, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.10.2006, *DJ* de 17.11.2006). No mesmo sentido: ADI 2.392-MC, Rel. Min. Moreira Alves, j. 28.03.2001, *DJ* de 1.º.08.2003; ADI 2.474, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 19.03.2003, *DJ* de 25.04.2003; ADI 2.638, Rel. Min. Eros Grau, j. 15.02.2006, *DJ* de 09.06.2006.

■ 9.13.3.3.7. **Iniciativa do processo legislativo de matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos Anuais**

Nos termos do **art. 165, I, II e III**, da CF/88, leis de **iniciativa do Poder Executivo** estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os

orçamentos anuais.

Decidiu o STF: “competência exclusiva do Poder Executivo iniciar o processo legislativo das matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos Anuais. Precedentes: ADI n. 103 e ADI n. 550” (ADI 1.759-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 12.03.1998, *DJ* de 06.04.2001).

■ **9.13.3.3.8. Pode o legitimado exclusivo ser compelido a deflagrar processo legislativo?**

De modo geral, o STF entendeu que não poderá o legitimado exclusivo ser “forçado” a deflagrar o processo legislativo, já que a fixação da competência reservada traz, implicitamente, a **discricionariedade** para decidir o momento adequado de encaminhamento do projeto de lei. [62](#)

Havendo prazo fixado na Constituição (ex.: art. 35, § 2.º, do ADCT), ou em emenda (ex.: art. 5.º da EC n. 42/2003), naturalmente o legitimado exclusivo poderá ser compelido a encaminhar o projeto de lei.

Por certo, poderá ser reconhecida a inconstitucionalidade por omissão na hipótese de não regulamentação de artigos da Constituição de eficácia limitada e desde que observado o critério da razoabilidade.

■ **9.13.3.3.9. Cabe emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada?**

O texto de 1988 restituiu aos parlamentares boa parte do poder de emenda que lhes havia sido retirado pelo regime (ditatorial) anterior.

Nos termos do **art. 63, I e II**, não será admitido aumento da despesa prevista **a)** nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3.º e 4.º; **b)** nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. *A contrario sensu*, então, será admitido o

poder de emenda parlamentar.

Dessa forma, de modo geral, entende o STF que cabe emenda parlamentar desde que respeitados os seguintes requisitos:

- os dispositivos introduzidos por emenda parlamentar não podem estar destituídos de **pertinência temática** com o projeto original;
- os dispositivos introduzidos por emenda parlamentar **não podem acarretar aumento de despesa** ao projeto original.

Assim, cabe emenda parlamentar nas hipóteses de **lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República**, desde que haja pertinência temática e, por regra, não acarrete aumento de despesas.

Excepcionalmente, contudo, nos projetos orçamentários de iniciativa exclusiva do Presidente da República, admitem-se emendas parlamentares mesmo que impliquem aumento de despesas (art. 63, I, c/c o art. 166, §§ 3.º e 4.º):

- ao **projeto de lei do orçamento anual** ou aos **projetos que o modifiquem** e desde que: **a)** sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; **b)** indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; **c)** sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei;
- ao **projeto de lei de diretrizes orçamentárias**, desde que as emendas parlamentares que acarretem aumento sejam compatíveis com o plano plurianual.

Avançando, nos termos do art. 63, II, também cabem emendas parlamentares, desde que haja pertinência temática e não acarretem aumento de despesas, aos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados (art. 51, IV — Resolução), do Senado Federal (art. 52, XIII — Resolução), dos Tribunais Federais (arts. 61, *caput*, e 96, II) e do Ministério Público (arts. 61, *caput*; 127, § 2.º; e 128, § 5.º).

Nesse sentido, “art. 34, § 1.º, da Lei estadual do Paraná n. 12.398/98, com redação dada pela Lei estadual n. 12.607/99. (...) **Inconstitucionalidade formal caracterizada**. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, § 1.º, II, ‘c’, da Constituição Federal” (ADI 2.791, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.08.2006, *DJ* de 24.11.2006). [63](#)

Finalmente, cabe alertar que, se for apresentada **emenda** a projeto de iniciativa reservada que não tenha observado o requisito da pertinência temática com o projeto original e/ou que acarrete aumento de despesa, eventual **sanção presidencial não convalidará o vício formal** caracterizador da inconstitucionalidade da lei. [64](#)

■ **9.13.3.3.10. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas em relação às normas fruto da manifestação do poder constituinte derivado decorrente?**

O STF tem entendido que as normas originárias das Constituições dos Estados ou da Lei Orgânica do DF, mas desde que **pela primeira vez**, podem tratar de normas que são de iniciativa reservada, como, para se ter um exemplo, normas que seriam de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo simétricas àquelas elencadas no art. 61, § 1.º, I e II.

Dessa forma, superando a sua jurisprudência, o STF pacificou que “as regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às **normas originárias das constituições estaduais** ou da **Lei Orgânica do Distrito Federal**” (ADI 1.167, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.11.2014, Plenário, *DJE* de 10.02.2015).

Conforme estudamos no *item 4.5.3*, o *poder constituinte derivado decorrente* dos Estados e do DF manifesta-se tanto de **modo inicial**, elaborando, pela primeira vez, a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do DF — e por isso também denominado “**instituidor**” ou “**institucionalizador**” —, como de **modo revisional**, modificando o texto da Constituição estadual ou da Lei Orgânica do DF — e, por isso, chamado de **segundo grau**.

O entendimento da Corte no sentido de não haver a exigência de se observar a regra da iniciativa reservada refere-se ao **poder constituinte derivado decorrente inicial**, ou seja, aquele que elabora a Constituição do Estado ou a Lei Orgânica do DF **pela primeira vez** (cf. **ADI 2.581**, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, j. 16.08.2007, Plenário, *DJE* de 15.08.2008). Nesse caso, enfatizamos, não estará caracterizada qualquer violação à regra da iniciativa reservada.

■ **9.13.3.3.11. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas, enquanto limites, pelo poder constituinte derivado reformador (PEC)?**

Não.

Entendemos que as únicas limitações que devem ser observadas em relação às emendas constitucionais são os já estudados limites ao poder de reforma.

Assim, as matérias de iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, II) podem ser tratadas por emendas constitucionais. É o que se verificou com a **EC n. 73/2013** (cf. *item 9.13.3.3.3*) ou, para se ter um outro importante exemplo, a **EC n. 74/2013**, que estabeleceu a autonomia da Defensoria Pública da União (cf. aprofundamento no *item 12.6.5*).

No caso específico das PECs, o constituinte permitiu a reforma da Constituição não apenas em razão de proposta encaminhada pelo Presidente da República, mas, indistintamente e de modo concorrente, por todos os indicados no art. 60, I, II e III. Assim, não encontramos fundamento na Constituição para se sustentar, em relação a determinadas matérias, a competência exclusiva do Presidente da República.

■ **9.13.3.3.12. Sanção presidencial convalida vício de iniciativa?**

Não.

Muito embora a regra contida na S. 5/STF, de 13.12.1963 (“a sanção do

projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo”), pode-se dizer que o seu conteúdo está **superado** desde o advento da EC n. 1/69 (art. 57, parágrafo único — cf. **Rp 890**, *RTJ* 69/625), bem como insubsistente em razão da CF/88 (**ADI 1.381-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.12.1995, Plenário, *DJ* de 06.06.2003).

Portanto, **sanção presidencial não convalida vício de iniciativa**. Trata-se de vício formal insanável, incurável. [65](#)

■ 9.13.3.4. *Iniciativa popular*

■ 9.13.3.4.1. *Aspectos gerais*

O art. 14, *caput*, da CF/88 prevê que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e **iniciativa popular**.

Trata-se de novidade introduzida pela CF/88, a exemplo do art. 71 da Carta italiana de 1948, estabelecendo a possibilidade de o eleitorado nacional deflagrar processo legislativo de **lei complementar** ou **ordinária**, mediante proposta de, no mínimo, 1% de todo o eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco Estados e, em cada um deles com não menos do que 3/10% dos seus eleitores (art. 61, § 2.º, c/c o art. 14, III, da CF/88 e Lei n. 9.709/98).

Portanto, a iniciativa popular caracteriza-se como uma forma direta de exercício do poder (que emana do povo — art. 1.º, parágrafo único), sem o intermédio de representantes, através de apresentação de projeto de lei, dando-se início ao processo legislativo de formação da lei.⁶⁶

O que deve ficar claro é que o aludido instituto serve apenas para dar o “*start*”, ou seja, tão só para deflagrar o processo legislativo, sendo que o Parlamento poderá rejeitar o projeto de lei ou, ainda, o que é pior, emendá-lo, desnaturando a essência do instituto. No mesmo sentido e pela mesma lógica, aprovado pelo parlamento o projeto de iniciativa popular, o Presidente da República poderá vetá-lo.

Poderíamos pensar que, havendo qualquer modificação, a lei aprovada tenha de passar por referendo popular, mas não é, infelizmente, a tese que vigora.

Esquematizando as regras para a iniciativa popular previstas no art. 61, § 2.º, da CF/88, temos:

■ **iniciativa?:** popular;

■ **de que forma?:** apresentação de projeto de lei **ordinária** ou

complementar à Câmara dos Deputados; [67](#) e [68](#)

■ **como deve ser apresentado o projeto de lei?:** o projeto de lei deve ser **subscrito** por, no mínimo, **1%** do eleitorado nacional;

■ **como deve estar disposto esse “1% do eleitorado nacional”?:** 1% do eleitorado nacional deve estar distribuído por, pelo menos, **5** Estados e, em cada Estado, não pode haver menos que **3/10%** dos seus eleitores, subscrevendo o projeto de lei.

Para se ter uma noção do número necessário, nas eleições de *outubro de 2014* o eleitorado nacional, informado pelo TSE (incluindo os cidadãos brasileiros residentes no exterior), era de **142.822.046** eleitores. Portanto, o número para a iniciativa popular seria de, pelo menos, **1.428.221**, obedecendo-se, ainda, às regras expostas na Constituição de percentual mínimo por Estado.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, diante desse rigorismo procedimental e numérico, qualifica a iniciativa popular como **“instituto decorativo”**. [69](#)

O art. 13, § 1.º, da Lei n. 9.709/98, no mesmo sentido do que já dizia o art. 252, VIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispõe que o projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a **um só assunto**, isso para facilitar a coleta de assinaturas e a exata compreensão do que se está assinando.

O art. 13, § 2.º, da Lei n. 9.709/98 prevê que o projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, que é a Casa iniciadora (sendo o Senado Federal a Casa revisora), por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação, sendo que o art. 14 estabelece que a Câmara dará seguimento à iniciativa popular consoante as normas do Regimento Interno.

Para aprofundar o assunto, o(a) amigo(a) concurseiro(a) poderá analisar o art. 252 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, bem como os arts. 24, II, “c”; 91, II; 105, IV, e 171, § 3.º, do Regimento Interno do Senado Federal.

■ 9.13.3.4.2. Existe algum exemplo de lei fruto de iniciativa popular?

Surge o grande questionamento: o Brasil tem tradição em projetos de iniciativa popular? Há alguma lei que teve a iniciativa popular nos termos do art. 61, § 2.º, da CF/88?

Existem somente *quatro* projetos de lei de iniciativa popular aprovados (com algumas observações, abaixo, sobre se, de fato, foram em sua essência de iniciativa popular), apresentados a seguir em ordem cronológica de aprovação:

■ **Lei n. 8.930/94:** conhecido como o **Projeto de Iniciativa Popular Glória Perez**, em razão do homicídio de sua filha, o documento reuniu mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas, culminando com a modificação da Lei de Crimes Hediondos. Cabe alertar, contudo, que, na prática, esse projeto foi encaminhado pelo Presidente da República, pela Mensagem n. 571, de 08.09.1993, que, autonomamente, já teria iniciativa para deflagrar o processo legislativo. No site da Câmara dos Deputados, o projeto aparece como sendo de coautoria do Executivo e da Iniciativa Popular. No site do Senado Federal, contudo, na tramitação legislativa aparece como sendo somente do Executivo;

■ **Lei n. 9.840/99:** conhecido como “**captação de sufrágio**”, buscou, nos termos de sua justificativa, “... dar mais condições para que a Justiça Eleitoral possa coibir com mais eficiência o crime de compra de votos de eleitores” (*DCD*, 15.09.1999, p. 41598). Iniciou-se com o lançamento do projeto “Combatendo a corrupção eleitoral”, em fevereiro de 1997, pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sendo apoiada a iniciativa por mais de 60 entidades.

Até 10.08.1999 tinha sido subscrito o projeto de iniciativa popular por **952.314** eleitores, sendo entregue ao Presidente da Câmara dos Deputados. O tempo era muito curto, pois se queria aprovar a nova regra para já ser aplicada nas eleições do ano 2000 e, ainda, faltavam votos para alcançar o percentual constitucional (à época, correspondente a 1 milhão e 60 mil assinaturas).

Diante dessa situação, faltando assinaturas e existindo o real risco de eventual

questionamento de sua validação técnica, o projeto foi subscrito pelo *Deputado Albérico Cordeiro* e outros 59 parlamentares, sendo aprovado em tempo recorde e passando as suas regras a ser aplicadas já a partir das eleições de 2000 (o Presidente da República sancionou a lei em 28.09.1999, que foi publicada no *DOU* de 29.09.1999, portanto um dia antes do prazo fatal para a sua aplicação no pleito de 1.º de outubro de 2000 — *vide* art. 16 da CF/88). [70](#)

Por fim, apenas a título de esclarecimento, cabe observar que a **ADI 2.942** questiona o art. 41-A da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), acrescentado pela Lei n. 9.840/99, [71](#) sendo alegada a tese de que a matéria prevista no referido artigo deveria ser objeto de **lei complementar**, e não lei ordinária, já que se estaria criando mais uma hipótese de inelegibilidade (art. 14, § 9.º, da CF/88).

O tema foi resolvido em outra ADI, conforme *Inf. 446/STF*: “o Tribunal julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro — PSB contra a expressão ‘cassação do registro ou do diploma’, constante do art. 41-A da Lei 9.504/97, pena cominada ao crime de captação de sufrágio nele definido. Na linha do que decidido no julgamento da ADI n. 3.305/DF (j. 13.9.2006), entendeu-se que a cominação da referida sanção não implica nova hipótese de inelegibilidade, não havendo, portanto, ofensa ao § 9.º do art. 14 da CF. De igual modo, afastou-se a alegação de afronta ao disposto nos §§ 10 e 11 do citado art. 14 da CF. Ressaltou-se, no ponto, que o procedimento da representação para a apuração da conduta descrita no art. 41-A da Lei 9.504/97 é o previsto nos incisos I a XIII do art. 22 da Lei Complementar 64/90, já que ela não implica declaração de inelegibilidade, mas apenas cassação do registro ou do diploma, diferentemente do que ocorre na ação de investigação judicial eleitoral, em relação à qual aplicam-se os incisos I e XV do art. 22 da aludida LC. Por isso, a decisão fundada no art. 41-A da Lei 9.504/97 tem eficácia imediata, não incidindo o que previsto no art. 15 da LC 64/90, que exige o trânsito em julgado da decisão para a declaração de inelegibilidade do candidato. Afirmou-se, por fim, que o art. 41-A foi introduzido na Lei 9.504/97, pela Lei 9.840/99, com o objetivo de combater as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto, isto é, proteger

a vontade do eleitor” ([ADI 3.592/DF](#), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.10.2006).

■ **Lei n. 11.124/2005:** conhecida como “**fundo nacional para moradia popular**”, a lei dispõe sobre o *Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social* (SNHIS), cria o *Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social* (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

Trata-se do **primeiro projeto de iniciativa popular da história brasileira** apresentado à Câmara dos Deputados (lembrar que o instituto da iniciativa popular foi introduzido pela CF/88) — PL n. 2.710/92-CD, que tramitou por mais de 13 anos. “O principal objetivo do Fundo é somar e articular todos os recursos para ações em habitação nos três níveis de governo — federal, estaduais e municipais —, e direcioná-los para atender as famílias de baixa renda.”⁷²

A Comissão de Constituição e Justiça, durante a tramitação do referido projeto de lei, que culminou na aprovação da Lei n. 11.124/2005, chegou a discutir eventual vício formal de iniciativa na medida em que, em tese, o dispositivo legal contém normas sobre *Administração Pública, criação de órgãos, atribuição de competências, gestão de recursos* etc., o que poderia levar ao entendimento de que só ao Presidente da República caberia iniciar o aludido processo legislativo, nos termos do art. 61, § 1.º, II, “a” e “e”.

Esse entendimento literal **não** nos parece o mais correto, como veremos a seguir, especialmente diante do sentido maior de titularidade do poder pelo povo, que elege o Presidente da República, à luz da interpretação sistemática do texto.

No entanto, esse tema ainda não foi enfrentado pelo STF e, de modo geral, para as provas preambulares, não vem sendo aceito o instituto da iniciativa popular em matérias de iniciativa **reservada** ou **exclusiva**.

■ **LC n. 135/2010 (“Ficha Limpa”):** muito embora tenha sido iniciada a discussão a partir de projeto originário do Executivo (*PLP 168/93*), o *Projeto de Lei Complementar n. 518/2009* (Câmara dos Deputados) foi encaminhado por diversos Deputados Federais, apoiado por 1 milhão e 700 mil assinaturas, com o objetivo de tramitar como projeto de iniciativa popular. Assim, puramente, não foi um projeto exclusivamente de iniciativa

popular, mas, sim, teve ampla aceitação da sociedade.

■ 9.13.3.4.3. **Conclusões iniciais**

Por todo o exposto, percebe-se que a **experiência brasileira** é muito **tímida**. Reconhecemos que os requisitos rígidos contribuem para essa situação (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, como vimos, fala em “**instituto decorativo**”). Contudo, na prática, temos certeza de que o instituto consagra a soberania popular e serve, ao menos, de **pressão** para que o Congresso Nacional priorize as matérias, mesmo quando o projeto é encampado por algum Parlamentar ou outro órgão que tenha a possibilidade da iniciativa legislativa.

Essa realidade, que demonstra a pouca participação popular nos projetos de lei, vem sendo, entretanto, discutida no Congresso Nacional, e há vários projetos no sentido de facilitar e viabilizar a *democracia participativa*, como a **PEC n. 2/99**, que diminui o percentual das assinaturas para 0,5% do eleitorado nacional, o **PL 4.764/2009**, que admite a assinatura digital (eletrônica) para o envio das propostas, o **PL 7.003/2010**, que possibilita o uso de urnas eletrônicas para a coleta das assinaturas, entre tantos outros.

Buscando minimizar essa realidade, tanto na Câmara como no Senado, já existem *Comissões Participativas*, destacando-se:

■ **Comissão de Legislação Participativa (art. 32, XII, do RICD):** possui, como campo temático ou área de atividade: *a)* sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos; *b)* pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea “a” desse inciso;

■ **Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (art. 102-E do RISF):** compete opinar sobre: I — sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos com representação política no Congresso Nacional; II — pareceres técnicos, exposições e

propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas no inciso I.

■ 9.13.3.4.4. *Iniciativa popular de “PEC”?*

Conquanto desejável, o sistema brasileiro **não** admitiu **expressamente** a iniciativa popular para propostas de emendas à Constituição (PEC), apesar de entendermos perfeitamente **cabível**, como se verá abaixo.

Ao contrário, de modo expresso, o exercício do poder constituinte derivado reformador foi direcionado para o rol de legitimados previsto no art. 60, I, II e III, da CF/88, consagrando a denominada **iniciativa concorrente**.

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, em excelente e recomendada monografia sobre o tema, observam que, “ao contrário do que foi previsto em relação ao processo legislativo de elaboração das leis (CF, art. 61, § 2.º), não foi contemplada pela vigente Carta da República a possibilidade de iniciativa popular no processo de reforma da Constituição, isto é, os cidadãos não dispõem de legitimidade para apresentar uma proposta de emenda à Constituição”.⁷³

Mônica de Melo também observa que “... projeto de lei de iniciativa popular não pode alterar normas constitucionais, uma vez que o instrumento próprio é a emenda constitucional, que possui iniciativa própria e diferenciada das outras espécies”.⁷⁴

No entanto, **com o máximo respeito**, ousamos discordar, apontando para uma linha mais ampla da regra prevista no art. 61, § 2.º.

Valemo-nos, para tanto, da interpretação sistemática, destacando o art. 1.º, parágrafo único, que permite o exercício do poder de forma **direta** pelo próprio povo, e o art. 14, III, ao estabelecer que a **soberania popular** será exercida mediante a iniciativa popular.

Nesse sentido, José Afonso da Silva pondera que a iniciativa popular para PEC pode vir a ser reconhecida “... com base em normas gerais e princípios fundamentais da Constituição”, apesar de não estar esse tipo de iniciativa popular “... especificamente estabelecido para emendas constitucionais como o

está para as leis (art. 61, § 2.º)”.[75](#)

E complementa afirmando que o instituto da iniciativa popular para PEC “... vai depender do desenvolvimento e da prática da democracia participativa que a Constituição alberga como um de seus princípios fundamentais”.[76](#)

Como responder nas provas de concursos públicos? Tratando-se de *prova escrita*, tranquilo: cada um vai desenvolver a linha de raciocínio pela admissibilidade (interpretação sistemática) ou não (interpretação literal). E na *prova preambular*? Com todo o respeito, espero que esse tipo de pergunta não apareça em nenhum concurso em prova preambular de múltipla escolha.

O que se pode perguntar é se a iniciativa popular de PEC foi prevista **expressamente** no texto da CF/88. A resposta é **não**. O que temos é a sua admissibilidade em razão de interpretação sistemática.

Cabe alertar, para ter exemplos, que, dos 26 Estados + o DF, **16**, portanto mais da metade, admitem, de **forma declarada** e **expressa** (*vide* quadro a seguir), a iniciativa popular para encaminhamento de PEC.

Outro exemplo é a Lei Orgânica do Município de São Paulo, que também admite o encaminhamento de emendas por iniciativa popular (art. 5.º, § 1.º, II).

Como outro exemplo, ainda, podemos citar a PEC n. 3/98 à Constituição do Estado do **Pará**, que, de maneira inédita, **por iniciativa popular**, suspendeu a **restrição** do passe livre às pessoas portadoras de deficiência, nos transportes públicos rodoviários e aquaviários, intermunicipais e municipais, no Pará, modificando o art. 249, VI, “a”, da Constituição do Estado.[77](#)

Quadro Comparativo das Constituições Estaduais

ESTADOS DA FEDERAÇÃO	PREVISÃO EXPRESSA DE INICIATIVA POPULAR DE “PEC” NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL? SIM	PREVISÃO EXPRESSA DE INICIATIVA POPULAR DE “PEC” NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL? NÃO

Acre	■ art. 53, III, da Constituição Estadual	
Alagoas	■ art. 85, IV, da Constituição Estadual	
Amapá	■ arts. 103, IV, e 110 da Constituição Estadual	
Amazonas	■ art. 32, IV, da Constituição Estadual	
Bahia	■ art. 31 da Constituição Estadual	
Ceará		■ não há previsão expressa na Constituição
DF	■ art. 70, III, da Lei Orgânica do DF	
Espírito Santo	■ art. 62, III, da Constituição Estadual	
Goiás	■ art. 19, IV, da Constituição Estadual	
Maranhão		■ não há previsão expressa na Constituição
Mato Grosso		■ não há previsão expressa na Constituição

Mato Grosso do Sul		■ não há previsão expressa na Constituição
Minas Gerais		■ não há previsão expressa na Constituição
Pará	■ art. 8.º, parágrafo único, da Constituição Estadual	
Paraíba	■ art. 62, IV — acrescentado pela EC n. 2/93 (Constituição Estadual)	
Paraná		■ não há previsão expressa na Constituição
Pernambuco	■ art. 17, III, da Constituição Estadual	
Piauí		■ não há previsão expressa na Constituição
Rio de Janeiro	■ art. 111, IV — acrescentado pela EC n. 56/2013 (Constituição Estadual)	
Rio Grande do Norte		■ não há previsão expressa na Constituição
Rio Grande do Sul	■ art. 58, IV, da Constituição Estadual	

Rondônia		■ não há previsão expressa na Constituição
Roraima	■ art. 39, IV, da Constituição Estadual	
Santa Catarina	■ art. 49, IV, da Constituição Estadual	
São Paulo	■ art. 22, IV, da Constituição Estadual	
Sergipe	■ art. 56, IV, da Constituição Estadual	
Tocantins		■ não há previsão expressa na Constituição

Canotilho, analisando a Constituição de Portugal, observa que “a iniciativa popular é um procedimento democrático que consiste em facultar ao povo (a uma percentagem de eleitores ou a um certo número de eleitores) a **iniciativa de uma proposta tendente à adoção de uma norma constitucional** ou legislativa”.⁷⁸

Parece uma linha bastante interessante de se pensar, especialmente se se fizer uma **interpretação sistemática** da Constituição, lembrando que a titularidade do poder pertence ao **povo**, nos termos do art. 1.º, parágrafo único, da CF/88, e que a **soberania popular** é exercida pelo plebiscito, pelo referendo e pela **iniciativa popular**.

Realizando pesquisa na jurisprudência do STF, encontramos apenas um único caso em que se analisava a possibilidade de PEC de iniciativa popular em âmbito

estadual, qual seja, o questionamento da constitucionalidade dos arts. 103, IV, e 110 da Constituição do Amapá, na **ADI 825-1**. No julgamento da liminar, o STF suspendeu a eficácia de outros dispositivos que também eram objeto de impugnação e não esses que tratavam da iniciativa popular (**matéria pendente de julgamento de mérito**).

Esperamos que o STF não julgue inconstitucional esse importante instrumento de democracia direta, de exercício do poder pelo próprio povo e de consolidação da soberania popular e implemento da cidadania.

■ 9.13.3.4.5. *Cabe iniciativa popular de matérias reservadas à iniciativa exclusiva de outros titulares?*

De modo geral, não se admite a iniciativa popular para matérias em relação às quais a Constituição fixou determinado titular para deflagrar o processo legislativo (iniciativa exclusiva ou reservada).

Como todos sabem, existe previsão de iniciativa reservada (exclusiva) para o Presidente da República (art. 61, § 1.º); o Poder Judiciário (ex., art. 93); as Mesas da Câmara e do Senado (arts. 51, IV, e 52, XIII) etc.

O único questionamento que vem surgindo é quanto à possibilidade ou não de iniciativa popular em matérias de **iniciativa reservada do Presidente da República** (em relação aos outros titulares, a dúvida estaria afastada).

Temos um exemplo concreto: conforme vimos, a Comissão de Constituição e Justiça, durante a tramitação do projeto de lei que culminou na aprovação da **Lei n. 11.124/2005** (de iniciativa popular), chegou a discutir eventual vício formal de iniciativa tendo em vista que a matéria tratada, nos termos do art. 61, § 1.º, II, “a” e “e”, seria de competência exclusiva, portanto, indelegável, do Presidente da República.

O entendimento da CCJ, tanto da CD como do SF, foi o de que não haveria vício de iniciativa. Isso porque o processo legislativo teria sido instaurado por iniciativa popular, lembrando que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes.

Parece-nos bastante sedutora essa tese. Vamos aguardar, contudo, eventual manifestação do STF sobre o assunto.

Para as provas, especialmente as preambulares, temos visto o entendimento de que, genericamente, não caberia iniciativa popular em matérias de iniciativa reservada. Não encontramos nenhuma prova que tenha feito pergunta no sentido de iniciativa popular em caso de iniciativa reservada do Presidente da República.

José Afonso da Silva, expressamente, ao falar sobre a iniciativa popular, observa que se trata de “... iniciativa legislativa que ingressa no campo das **iniciativas concorrentes**. **Não** se admite iniciativa legislativa popular em **matéria reservada** à iniciativa exclusiva de outros titulares...”.⁷⁹

Fica o tema para ser discutido...

■ 9.13.3.4.6. *Iniciativa popular e as espécies normativas: esquematização*

Nesse tópico, procuramos sistematizar o cabimento de iniciativa popular em relação às espécies normativas do art. 59. Então vejamos:

ESPÉCIE NORMATIVA	CABE INICIATIVA POPULAR?
emendas à Constituição	■ apesar de não haver previsão expressa na CF/88, admite-se , desde que se faça a já comentada e discutida interpretação sistemática do texto
Leis complementares	■ a CF expressamente admite nos termos do art. 61, § 2.º
Leis ordinárias	■ a CF expressamente admite nos termos do art. 61, § 2.º
Leis delegadas	■ não se admite , já que a delegação, nos termos do art. 68, deve ser solicitada pelo Presidente da República e concedida, por meio

	de resolução , pelo Congresso Nacional ao Presidente da República e somente a ele
Medidas provisórias	■ não se admite , já que a titularidade para a edição de MP é exclusiva do Chefe do Executivo nos casos de relevância e urgência e nos termos do art. 62 da CF/88
Decretos legislativos	■ não se admite , já que o decreto legislativo é o instrumento pelo qual o Congresso Nacional materializa as suas competências exclusivas previstas no art. 49 da CF/88
Resoluções	■ não se admite , já que a resolução é o instrumento pelo qual se instrumentalizam as atribuições da CD, do SF ou algumas comuns fixadas no regimento interno do Congresso Nacional

■ 9.13.3.4.7. *Iniciativa popular em âmbito estadual e municipal*

A iniciativa popular em **âmbito estadual** está prevista no art. 27, § 4.º, que transfere a sua regulamentação para lei. Apenas a título de ilustração, a Constituição do Estado de São Paulo regulamenta a matéria em seu art. 24, § 3.º, trazendo diversas regras.

O art. 29, XIII, da CF/88 fixa as regras para a iniciativa popular em **âmbito municipal**, dispondo **de modo diferente** da iniciativa popular em âmbito federal. Vejamos: “iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, **5% do eleitorado**”.

■ 9.13.3.5. *Iniciativa conjunta: ainda persiste, tendo em vista a Reforma da Previdência (EC n. 41/2003)?*

Na hipótese de **iniciativa conjunta**, existe uma presunção de **consenso de**

vontades, estabelecendo a CF competência para que diversas pessoas, **juntas**, deflagrem o processo legislativo.

Como exemplo, lembramos a inovação introduzida pela EC n. 19/98, que determinou a iniciativa conjunta para a elaboração de lei que fixasse o subsídio dos Ministros do STF, **teto máximo previsto no art. 37, XI**.

Referido teto máximo, correspondente ao subsídio dos Ministros do STF, deveria, de acordo com a **regra anterior**, ser fixado por lei federal, ordinária (art. 47 da CF/88), a ser editada pelo Congresso Nacional, de **iniciativa conjunta** do Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado Federal e do Presidente do STF (art. 48, XV).

A **EC n. 41/2003**, em contrapartida, afastou a regra da iniciativa conjunta, como se verá no próximo item, prevendo o novo procedimento de **iniciativa exclusiva do Presidente do STF** para se deflagrar o processo legislativo que fixa o subsídio dos Ministros do STF — teto do funcionalismo (art. 48, XV, c/c o art. 96, II, “b”).

■ 9.13.3.6. *Iniciativa para fixação do subsídio dos Ministros do STF — teto do funcionalismo — art. 48, XV, c/c o art. 96, II, “b”*

Conforme visto no item anterior, a **Reforma da Previdência** (EC n. 41/2003) trouxe **nova regra** no tocante à iniciativa do projeto de lei para a fixação do subsídio dos Ministros do STF.

De acordo com o art. 96, II, “b”, a iniciativa de projeto de lei fixando a remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, cabe aos **Tribunais**.

Assim, a iniciativa do projeto de lei, que deverá ser analisado pelo Congresso Nacional (art. 48, XV), para a fixação do teto do funcionalismo (subsídio mensal dos Ministros do STF) cabe ao **STF**.

Passemos a analisar algumas particularidades sobre o **teto do funcionalismo**.

Como se sabe, de conformidade com o inciso XI do art. 37, a remuneração e

o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, **incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal**, aplicando-se como limite, nos **Municípios**, o subsídio do **Prefeito**, e, nos **Estados** e no **Distrito Federal**, o subsídio mensal do **Governador** no âmbito do **Poder Executivo**, o subsídio dos **Deputados Estaduais e Distritais** no âmbito do **Poder Legislativo** e o subsídio dos **Desembargadores do Tribunal de Justiça**, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF, no âmbito do **Poder Judiciário**, aplicável esse limite aos membros do MP, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.

O art. 37, § 9.º, acrescentado pela EC n. 19/98, estabelece que o disposto no inciso XI do art. 37 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Abrandando a regra geral do art. 37, XI (que incluía no teto as “... **vantagens pessoais** ou de **qualquer outra natureza**”), a **EC n. 47/2005**, inserindo o § 11 no art. 37, preceituou não serem computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as **parcelas de caráter indenizatório previstas em lei**. Trata-se de norma de eficácia limitada, que, contudo, tem efetividade e efeitos em razão da regra de integração prevista no art. 4.º da EC n. 47/2005.

Isso porque, segundo essa regra de transição, “enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do *caput* do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional n. 41, de

2003”.

Outra medida visando **amenizar** o impacto da **Reforma da Previdência** (EC n. 41/2003) e em fortalecimento da **autonomia federativa**, a EC n. 47/2005 introduziu no art. 37 o § 12, permitindo que os Estados e o DF, por critérios de conveniência e oportunidade, fixem, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, um **teto único** equivalente ao subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF. Essa regra, contudo, não se aplica aos Deputados Estaduais, Distritais e Vereadores.

Cumprir ainda referir que, conforme o art. 8.º da EC n. 41/2003, até que fosse estabelecido o teto do funcionalismo por lei federal ordinária de iniciativa do Presidente do STF (art. 96, II, “b” — competência do STF, sendo que o projeto de lei se iniciaria na Câmara dos Deputados), aprovada pelo Congresso Nacional (art. 48, XV), este seria o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação da Emenda, nos exatos termos da nova redação conferida ao inciso XI do art. 37, acima reproduzida, lembrando, ainda, a previsão dos subvetos.

Em 05.02.2004, em *Sessão Administrativa* convocada pelo então Presidente do STF, Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do *Processo Administrativo n. 319.269*, ficou decidido que o teto salarial do STF (até que viesse a lei) seria de **R\$ 19.115,19**.

Três foram as hipóteses analisadas pelos Ministros: **a) R\$ 17.343,71** — subsídio básico dos Ministros do STF; **b) R\$ 19.115,19** — valor recebido pelo Presidente do STF, já que o Decreto-lei n. 1.525/77, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 1.604/78, manda acrescentar à representação mensal devida ao Presidente da Corte o percentual de 20%, correspondente a R\$ 1.771,48; **c) R\$ 23.213,89** — valor decorrente da *gratificação de presença* devida na forma da Lei n. 8.350/91 [80](#) e pago aos Ministros do STF que atuam perante o TSE (art. 119, I, “a”, da CF/88).

Assim, como visto, em cumprimento ao art. 8.º da EC n. 41/2003, até que viesse a lei, o teto máximo do funcionalismo seria o valor pago ao Ministro

Presidente do STF, de **R\$ 19.115,19**.

No referido julgamento, o Tribunal entendeu, contudo, que os três Ministros que acumulam função perante o TSE **não** terão os seus vencimentos reduzidos, já que, por determinação constitucional, recebem **gratificação especial**, não podendo uma regra fixar a acumulação (de cargos e vencimentos) e outra proibi-la.

Em suas palavras, justificadoras da não redução em relação aos Ministros do TSE, o Ministro Maurício Corrêa assim se manifestou: “invoco a práxis da interpretação harmônica e teleológica do texto constitucional para concluir que, na **situação particular** da acumulação dos cargos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, autorizada e mesmo determinada pelo artigo 119 da Constituição, não se aplica a cumulação das remunerações para fixação do teto ou, em outras palavras, as remunerações respectivas, para fins da aplicação do inciso XI do artigo 37, que deverão, nesse caso específico, ser consideradas isoladamente. Somente estarão sujeitas à redução se, em uma ou outra situação, *per se*, ultrapassar o limite fixado pela EC 41/2003. É claro que tal raciocínio se aplica, por decorrência lógica, a todas as situações de composição da Justiça Eleitoral” (cf. íntegra do voto: *Notícias STF*, 10.02.2004 — 15h48).

Posteriormente, nos termos do art. 96, II, “b”, o PL n. 4.651/2004, de iniciativa do Presidente do STF, fixou o teto em **R\$ 21.500,00**, a partir de 1.º.01.2005, e em **R\$ 24.500,00**, a partir de 1.º.01.2006 (*Notícias STF*, 21.12.2004 — 17h36). Referido projeto de lei foi convertido na **Lei n. 11.143**, de 26.07.2005, que entrou em vigor na data de sua publicação.

Tendo em vista o aumento de 5% fixado pela Lei n. 12.041, de 08.10.2009, a partir de 1.º.09.2009, o subsídio mensal dos Ministros do STF e, em decorrência, o teto do funcionalismo, passou a ser de R\$ 25.725,00, prevendo-se, na referida lei, um novo aumento de 3,88% a partir de 1.º.02.2010, quando se atingiu o valor de **R\$ 26.723,13**.

Finalmente, as **Leis ns. 12.771/2012** e **13.091/2015** fixaram novos valores para o subsídio de Ministros do STF e, portanto, para o teto do funcionalismo.

Vejamos:

- **R\$ 28.059,29:** a partir de 1.º.01.2013;
- **R\$ 29.462,25:** a partir de 1.º.01.2014; e
- **R\$ 33.763,00:** a partir de 1.º.01.2015.

■ **9.13.3.7. Algumas peculiaridades a serem observadas**

■ **9.13.3.7.1. Organização do Ministério Público**

Quando descrevemos as hipóteses de iniciativa privativa, lembramos o art. 61, § 1.º, que trata das matérias de competência privativa do Presidente da República.

Apesar dessa previsão expressa, no tocante à **iniciativa para apresentação de projeto de lei complementar de organização do Ministério Público da União** (art. 61, § 1.º, II, “d”), a CF/88 estabeleceu competência “**concorrente**” entre o **Presidente da República** e o **Procurador-Geral da República**, conforme pode ser observado pela leitura do art. 128, § 5.º. Assim, a matéria sobre a organização do Ministério Público da União terá iniciativa legislativa concorrente do Presidente da República com o Procurador-Geral da República. Nesse caso José Afonso da Silva chega a falar de uma espécie de “**iniciativa compartilhada**”.⁸¹

Tendo em conta a necessária **observância compulsória** pelos Estados-Membros e pelo DF das regras básicas de processo legislativo federal, também em âmbito estadual e distrital dever-se-á observar a regra da **iniciativa compartilhada**.

Assim, no **âmbito estadual**, concorrem para legislar, mediante **lei complementar**, sobre **normas específicas** de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público local, o Governador do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, lembrando serem de iniciativa reservada do Presidente da República as leis que disponham sobre **normas gerais** (no caso, a **Lei n.**

8.625/93 — Lei Orgânica Nacional do Ministério Público — LONMP — cf. art. 61, § 1.º, II, “d” — parte final). [82](#)

Em igual medida, em **âmbito distrital**, em face da regra do art. 21, XIII (que confere competência à União para organizar e manter o MP do DF e dos Territórios), e a do art. 128, I (que aloca o MP do DF e dos Territórios como ramo do MP da União), a iniciativa da lei complementar será **compartilhada** entre o **Presidente da República** e o **Procurador-Geral da República**, perante o Congresso Nacional (e **não** entre o Governador do DF e o Procurador-Geral de Justiça, conforme se observa em âmbito estadual). Nesse sentido, o art. 2.º, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93 estabelece que a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios serão objeto da **Lei Orgânica do Ministério Público da União** (no caso, a **LC n. 75/93**). [83](#)

Finalmente, no tocante ao **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas**, por entender o STF que se trata de **Ministério Público especial (art. 130)**, não integrante do MP comum, a iniciativa de lei sobre a sua organização será privativa da respectiva **Corte de Contas**.

■ **9.13.3.7.2. Proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67 — princípio da irrepetibilidade)**

O **art. 67** da CF/88 dispõe que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da **maioria absoluta dos membros** de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Trata-se do chamado **princípio da irrepetibilidade dos projetos rejeitados na mesma sessão legislativa**, cuja origem remonta ao art. 40 da Constituição de 1891.

Como veremos, deflagrado o processo legislativo, se na fase de *discussão e votação* o projeto de lei **não** for aprovado, ou mesmo se vetado e mantido o veto pelo Parlamento (o que corresponderia a uma não aprovação), como **regra**

geral só poderá ser reapresentado na sessão legislativa seguinte (lembrar que a sessão legislativa é o período anual em que os parlamentares se reúnem em Brasília, cf. o art. 57, *caput*).

No entanto, através da proposta da **maioria absoluta dos membros** de qualquer das Casas do Congresso Nacional, o projeto de lei poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa, surgindo, assim, uma nova hipótese de **iniciativa para o processo legislativo**.

Algumas questões podem ser levantadas:

■ **e se o novo projeto de lei, cuja iniciativa seguiu o procedimento do art. 67, for novamente rejeitado? Poderá a matéria ser reapresentada, na forma do art. 67, na mesma sessão legislativa, por uma segunda vez?**

Parece-nos que **sim**. Não há, pelo menos do ponto de vista da regra do art. 67, uma limitação de quantidade de vezes para a reapresentação do projeto. O único requisito que se fixa é o *quorum* qualificado da maioria absoluta, surgindo, pois, uma exceção ao princípio da irrepetibilidade dos projetos rejeitados.

■ **e em relação às matérias de iniciativa reservada ou exclusiva?**

Conforme vimos, algumas matérias são de iniciativa *privativa* (ou melhor, **exclusiva** ou **reservada**) de determinadas pessoas ou órgãos, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por elas, sob pena de se configurar **vício formal de iniciativa**, caracterizador da inconstitucionalidade do referido ato normativo.

Dessa maneira, como a matéria só poderá ser encaminhada pelo titular da iniciativa reservada, entendemos que a regra do art. 67 **não** poderá ser aplicada.

Em **matérias de iniciativa reservada**, portanto, o projeto de lei rejeitado **só poderá ser reapresentado na sessão legislativa seguinte**, pois não se conseguiria o *quorum* qualificado da maioria absoluta, sob pena de se caracterizar vício formal de inconstitucionalidade por violação ao princípio da irrepetibilidade.

Nesse caso, então, pode-se afirmar que o **princípio da irrepetibilidade é**

absoluto.

■ **e em relação às matérias constantes de projeto de lei rejeitado pelo CN, poderá o Presidente da República veicular a mesma matéria por MP?**

Entendemos que **não**, pois estaria sendo violada a regra do art. 67 e o princípio da separação de Poderes e integridade da ordem democrática. A única forma de reapresentar matéria constante de projeto de lei rejeitado seria somente mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

■ **e em relação à MP que veicule matéria constante de outra MP anteriormente rejeitada pelo CN?**

Também entendemos que **não** poderá o Presidente apresentar nova MP constante de outra MP anteriormente rejeitada, sob pena de se violar a regra do art. 67. [84](#)

■ **9.13.3.7.3. Iniciativa parlamentar ou extraparlamentar**

Essa classificação é pouco cobrada nos concursos, mas convém explicá-la, a fim de evitar surpresas no dia das provas. Segundo Alexandre de Moraes, “diz-se **parlamentar** a prerrogativa que a Constituição confere a todos os membros do Congresso Nacional (Deputados Federais/Senadores da República) de apresentação de projetos de lei. Diz-se, por outro lado, iniciativa **extraparlamentar** àquela conferida ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais Superiores, ao Ministério Público e aos cidadãos (iniciativa popular de lei)”. [85](#)

■ **9.13.4. Fase constitutiva**

Nessa segunda fase do processo legislativo, teremos a conjugação de vontades, tanto do legislativo (deliberação parlamentar — discussão e votação) como do executivo (deliberação executiva — sanção ou veto).

■ 9.13.4.1. *Deliberação parlamentar — discussão e votação*

Como regra geral, em decorrência do **bicameralismo federativo**, tratando-se de processo legislativo de lei federal, sempre haverá a apreciação de duas casas: a **casa iniciadora** e a **casa revisora**. Assim, para que o projeto de lei seja apreciado pelo Chefe do Executivo, necessariamente, deverá ter sido, previamente, apreciado e aprovado pelas duas Casas — a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

■ 9.13.4.1.1. *O projeto começa na Câmara ou no Senado?*

Para solucionar essa questão, o art. 64, *caput*, é expresso ao delimitar que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do **Presidente da República**, do **Supremo Tribunal Federal** e dos **Tribunais Superiores** terão início na Câmara dos Deputados. A esse rol acrescentaríamos os projetos de **iniciativa concorrente dos Deputados** ou de **Comissões da Câmara**, os de iniciativa do **Procurador-Geral da República** e, naturalmente, os de **iniciativa popular** (art. 61, § 2.º), que, como já visto, também terão início na **Câmara dos Deputados**, sendo esta, portanto, a *casa iniciadora* e o Senado Federal, em todas essas hipóteses lembradas, a *casa revisora*.

Perante o **Senado Federal** são propostos somente os projetos de lei de iniciativa dos **Senadores** ou de **Comissões do Senado**, funcionando, nesses casos, a Câmara dos Deputados como Casa revisora.

■ 9.13.4.1.2. *Apreciação pelas Comissões*

Iniciado o processo legislativo, o projeto de lei passa à apreciação pelas Comissões.

Basicamente, o projeto deverá ser visto, em primeiro lugar, por uma **comissão temática**, que analisará a **matéria** da proposição, e, em seguida, pela **Comissão de Constituição e Justiça**, que examinará, dentre outros aspectos, a

sua **constitucionalidade** (cf., por exemplo, a previsão dessa ordem nos termos do art. 53 do *RICD*).

Quando envolver *aspectos financeiros ou orçamentário público*, depois da comissão temática e antes da CCJ, o projeto será apreciado pela *Comissão de Finanças e Tributação*, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária (art. 53 do *RICD*).

É de observar que essa nova regra, qual seja, a CCJ apreciar o projeto depois da Comissão temática (matéria), foi introduzida pela *Resolução n. 10/91* ao *RICD*.

Conforme anotou Casseb, “é importante notar que a ordem atual da participação das comissões que comporta, em primeiro lugar, o exame dos projetos pelas comissões temáticas e depois pela Comissão de Constituição e Justiça decorreu da necessidade de se eliminar uma considerável falha do procedimento antigo. No período em que a CCJC atuava antes das comissões temáticas, verificou-se que a análise da constitucionalidade das proposições restava prejudicada, pois os projetos sofriam grandes modificações promovidas pelas comissões técnicas. Esse fato provocou a reformulação e o aperfeiçoamento da ordem de tramitação, haja vista que a avaliação realizada pela CCJC acontece após a atuação das comissões que examinam o mérito dos projetos”.⁸⁶

Além disso, sob o aspecto da operacionalidade, muitas matérias que eram apreciadas pela CCJ, quando pela **regra anterior** ela se manifestava antes da Comissão temática, não vinham a ser aprovadas, levando a um desperdício de tempo e acúmulo de atividades daquela Comissão.

Portanto, em nosso entender, muito bem-vinda a modificação regimental.

Lembramos que as comissões, em razão da matéria de sua competência, poderão, além de discutir e emitir pareceres sobre o projeto de lei, aprová-los, desde que, na forma do regimento interno da Casa, haja dispensa da competência do plenário (**delegação interna corporis**) e inexistir, também, interposição de **recurso de 1/10 dos membros da Casa**, hipótese em que será inviável a votação do projeto de lei pela comissão temática (art. 58, § 2.º, I),

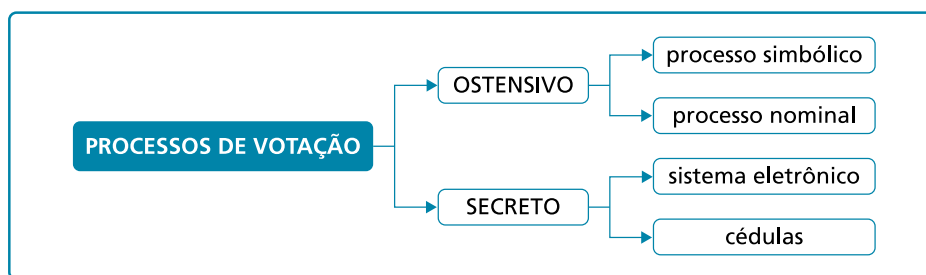
sendo esta, necessariamente, transferida para o plenário da Casa.

Para se ter um exemplo, o art. 24, II, do *RICD* deixa claro que **não** poderão ser objeto de aprovação nas comissões temáticas (em razão da matéria), afetando-os ao Plenário, ou seja, não poderão ser objeto de delegação *interna corporis*, os projetos:

- de lei complementar;
- de código;
- de iniciativa popular;
- de Comissão;
- relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 1.º do art. 68 da Constituição Federal;
- oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas;
- que tenham recebido pareceres divergentes;
- em regime de urgência;
- e poderíamos acrescentar, por exemplo, as propostas de emenda à Constituição (PEC), que exigem *quorum* de 3/5 dos membros, em cada Casa e em 2 turnos (art. 60, § 2.º, da CF/88).

Na hipótese de apreciação pelo Plenário, o parecer das **Comissões Temáticas** é **opinativo**, já que a matéria será ainda discutida e votada. Contudo, o parecer da *CCJ* quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria será **terminativo**, assim como o da *Comissão de Finanças e Tributação*, quando de sua manifestação sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição, salvo provimento de **recurso** a ser apreciado preliminarmente pelo Plenário, nos termos regimentais.

■ 9.13.4.1.3. *Processos de votação*



A votação poderá ser **ostensiva**, adotando-se o *processo simbólico* ou o *nominal*, e **secreta**, por meio do *sistema eletrônico* ou de *cédulas*.

No processo **simbólico**, que será utilizado na votação das proposições em geral, os parlamentares das respectivas Casas, para aprovar a matéria, permanecerão sentados, levantando-se apenas os que votarem pela rejeição.

Regimentalmente, se for requerida **verificação da votação**, será ela repetida pelo **processo nominal**.

Segundo o art. 186 do *RICD*, o **processo nominal** (pelo sistema eletrônico de votos) será utilizado:

- nos casos em que seja exigido *quorum* especial de votação;
- por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado;
- quando houver pedido de verificação de votação, respeitado o que prescreve o § 4.º do artigo anterior;
- nos demais casos expressos neste Regimento.

Por sua vez, o art. 188 do *RICD* estabelece que a votação por **escrutínio secreto** far-se-á pelo sistema eletrônico, nos seguintes casos:

- deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades de Deputado, nas condições previstas no § 8.º do art. 53 da Constituição Federal;
- por decisão do Plenário, a requerimento de um décimo dos membros da Casa ou de Líderes que representem este número, formulado antes de iniciada a Ordem do Dia;
- para eleição do Presidente e demais membros da Mesa Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de Comissões Permanentes e Temporárias,

dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos 2 (dois) cidadãos que irão integrar o Conselho da República e nas demais eleições;

■ no caso de pronunciamento sobre a perda de mandato de Deputado ou suspensão das imunidades constitucionais dos membros da Casa durante o estado de sítio. **CAUTION:** muito embora o *RICD* tenha sofrido modificação pela Res. n. 47/2013 para se ajustar à **EC n. 76/2013**, que **aboluiu a votação secreta** nos casos de **perda do mandato de Deputado ou Senador**, entendemos que esse dispositivo regimental, mantido na referida atualização, não mais encontra fundamento na Constituição. [87](#)

A **votação secreta** realizar-se-á pelo sistema eletrônico, salvo nas eleições em que se implementará por meio de **cédulas**.

■ 9.13.4.1.4. A Casa revisora

Rejeitado o projeto na **Casa Iniciadora**, será arquivado. Contudo, se **aprovado** (seja pelas Comissões Temáticas, nas hipóteses permitidas, seja pelo plenário da Casa), ele seguirá para a **Casa revisora**, passando, também, pelas Comissões, e, ao final, a Casa revisora poderá **aprová-lo, rejeitá-lo** ou **emendá-lo**:

■ **aprovado** o projeto de lei pela Casa revisora, *em um só turno de discussão e votação* (regra geral para leis ordinárias e complementares), será ele enviado para **sanção** ou **veto** do Chefe do Executivo;

■ **rejeitado** o projeto de lei, ou seja, caso a Casa revisora não o aprove, será ele **arquivado**, só podendo ser reapresentado na mesma sessão legislativa (anual), mediante proposta da *maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional* (art. 67), ou, sem essa formalidade, se a reapresentação for na sessão legislativa seguinte;

■ **emendado**, vale dizer, na hipótese de ter sido alterado o projeto inicial, a **emenda**, e somente o que foi modificado, deverá ser apreciada pela Casa iniciadora (art. 65, parágrafo único, da CF/88), sendo vedada a apresentação de emenda à emenda (**subemenda**).

Nessa hipótese, se a Casa iniciadora aceitar a emenda introduzida pela Casa revisora, assim seguirá o projeto para a deliberação executiva.

Contudo, se a Casa iniciadora rejeitar a emenda, o projeto, em sua redação original, que havia sido estabelecida pela Casa iniciadora, assim seguirá para a apreciação executiva.

Daí poder-se afirmar que no processo legislativo de elaboração de leis no sistema brasileiro haverá **predominância da Casa iniciadora sobre a revisora**.

Posteriormente, havendo aprovação do projeto de lei, este será encaminhado para o **autógrafo**, ou seja, a reprodução de todo trâmite legislativo e o conteúdo final do projeto aprovado e/ou emendado, para posterior sanção ou veto presidencial, promulgação (no caso de emendas à Constituição) ou à outra Casa.

■ 9.13.4.1.5. *Espécies de emendas*

De acordo com o art. 118 do *RICD*, as emendas serão *supressivas*, *aglutinativas*, *substitutivas*, *modificativas* ou *aditivas*:

■ **supressiva:** é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição;

■ **aglutinativa:** é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos;

■ **substitutiva:** é a apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, denominando-se “substitutiva” quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa;

■ **modificativa:** é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente;

■ **aditiva:** é a que se acrescenta a outra proposição;

■ **de redação:** a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto.

■ 9.13.4.1.6. *Algumas outras regras fundamentais*

■ **emendas a projeto de lei:** regra geral, conforme visto, é perfeitamente possível a inclusão de emendas ao projeto de lei. No entanto, distanciando-se dessa regra, não será admitida emenda a projeto de lei que aumente a despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República (ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3.º e 4.º) (cf. *item 9.13.3.3.9*), bem como nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público (art. 63, I e II);

■ **processo legislativo sumário ou regime de urgência constitucional:** o Presidente da República, nos projetos de sua iniciativa, poderá solicitar **urgência** na apreciação a ser realizada pelos congressistas. Como visto, a discussão iniciar-se-á na Câmara dos Deputados (art. 64, *caput*), devendo ser apreciada em 45 dias. Seguirá, então, para o Senado Federal, que também terá o prazo de 45 dias para apreciar a matéria. Em caso de emenda pelo Senado, sua apreciação será feita no prazo de 10 dias pela Câmara dos Deputados (art. 64, §§ 1.º a 3.º), vedando-se, é claro, como já visto, qualquer subemenda. Percebe-se, então, que o **procedimento sumário** tem prazo de, no máximo, **100 dias** (45 dias em cada casa + 10 dias em caso de emenda do Senado Federal a ser apreciada pela Câmara dos Deputados).

Lembramos que os referidos prazos **não** correm durante o período de **recesso** do Congresso Nacional (**recesso**, recorde-se, é o período fora da sessão legislativa ordinária e que vai, consoante a nova regra trazida pela **EC n. 50/2006** — que modificou o art. 57, *caput* — de **18 a 31 de julho** e de **23 de dezembro até 1.º de fevereiro** do ano seguinte) nem se aplicam aos projetos de **código** (art. 64, § 4.º).

Outra regra importante é a prevista no art. 64, § 2.º, na redação determinada pela **EC n. 32/2001**, segundo a qual, tramitando um processo sob o **regime de urgência**, se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até **45 dias**, **sobrestar-se-ão** todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das

que tenham prazo constitucional determinado (como exemplo, o prazo fixado para a apreciação das **medidas provisórias**, determinado na CF/88, em **60 dias**, prorrogáveis por mais **60 dias**, nos termos do art. 62, § 3.º), até que se ultime a votação.

Além dos projetos de iniciativa do Presidente da República, quando há solicitação de tramitação urgente, há, ainda, previstos na Constituição Federal, os casos de apreciação de **atos de outorga ou renovação de concessão, permissão ou autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens**, que também são projetos que tramitam sob o regime de urgência (cf. art. 223, § 1.º), seguindo os prazos do art. 64, §§ 2.º e 4.º.

Por fim, apenas esclarecemos que, além dos casos dos projetos que tramitam sob o **regime de urgência**, constitucionalmente previstos e acima comentados, há hipóteses às quais, **regimentalmente**, se estabelece a possibilidade de requerer urgência na votação de determinadas matérias. No entanto, nessas situações, a previsão é **regimental e não constitucional** (cf. arts. 336 do RISF e 152 do RICD), seguindo-se as peculiaridades de cada regimento interno.

Lembramos, ainda, a previsão de **regime de urgência** também em **legislação infraconstitucional**, como, para se ter um exemplo, é o caso da tramitação de decreto legislativo (art. 49, II, CF/88) para o Congresso Nacional autorizar o trânsito ou permanência de forças estrangeiras no território nacional (art. 3.º, II, da **LC n. 90/97**).

■ **9.13.4.2. Deliberação executiva — sanção e veto**

Terminada a fase de discussão e votação, aprovado o projeto de lei, deverá ele ser encaminhado para a apreciação do Chefe do Executivo. Recebendo o projeto de lei, o Presidente da República o **sancionará** ou o **vetará**.

■ **9.13.4.2.1. Sanção**

Em caso de **concordância**, de **aquiescência**, o Presidente da República

sancionará o projeto de lei. Sanção é o mesmo que **anuência**, **aceitação**, sendo esse o momento em que o projeto de lei se transforma em lei, já que, como se verá, o que se promulga é a lei.

A **sanção** poderá ser **expressa** ou **tácita**.

Sanção expressa é quando o Chefe do Executivo deliberadamente manifesta a sua concordância. Contudo, na *sanção tácita*, recebido o projeto, se ele não se manifestar no prazo de 15 dias úteis, o seu silêncio importará sanção. É o famoso “quem cala, consente”, ou seja, ficando silente, é como se o Chefe do Executivo não discordasse do projeto encaminhado pelo Legislativo.

Conforme vimos, **sanção presidencial não convalida vício formal subjetivo de iniciativa**, ou seja, em se tratando, por exemplo, de projeto cuja iniciativa seja reservada ao Presidente da República e encaminhada por um Deputado, a sanção não corrige o vício, que é insanável (cf. *item 9.13.3.3.12*).

E qual o **prazo** para o Presidente sancionar o projeto de lei?

Apesar de não haver previsão expressa, sabendo que o Chefe do Executivo tem 15 dias úteis para vetar o projeto de lei e que o seu silêncio importará sanção, temos de afirmar que o prazo para sancioná-lo será, também, de 15 dias úteis.

Convém alertar que nem todos os projetos são sancionáveis.

Nos termos do art. 48, dispensa-se a sanção e, portanto, não há que se falar em veto, nos projetos que versam sobre as matérias estabelecidas nos arts. **49** (*competência exclusiva do Congresso Nacional*), **51** (*competência privativa da CD*), **52** (*competência privativa do SF*) e, ainda, nas propostas de emenda à Constituição (**PEC**).

O instituto da sanção e, portanto, o momento de deliberação executiva deverão implementar-se mesmo em caso de projeto de iniciativa do Presidente que não tenha sido alterado pelo Parlamento.

Parece razoável imaginar que também nos projetos de lei de sua iniciativa o Presidente possa, agora, em fase mais madura do procedimento, vetá-lo, devendo, assim, ser, necessariamente, aberta a fase de deliberação executiva, até porque o art. 66, *caput*, é categórico ao afirmar que a Casa na qual tenha sido

concluída a votação (*e não distingue o tipo de iniciativa*) **enviará** o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

■ 9.13.4.2.2. Regras gerais sobre o veto

Em caso de **discordância**, poderá o Presidente da República **vetar** o projeto de lei, total ou parcialmente, observadas as seguintes regras:

■ **prazo para vetar:** 15 dias úteis, contados da data do recebimento;

■ **tipos de veto:** total ou parcial. Ou se veta todo o projeto de lei (veto total), ou somente parte dele. O veto parcial só abrangerá **texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea**. Assim, pode-se afirmar que **não** existe **veto de palavras**, o que poderia alterar, profundamente, o sentido do texto. Na hipótese de veto parcial, haverá análise pelo Congresso Nacional apenas da parte vetada, o que significa que a parte não vetada, que será promulgada e publicada, poderá entrar em vigor em momento anterior à referida parte vetada (veto parcial), se este vier a ser derrubado;

■ **motivos do veto:** vetando o projeto de lei, total ou parcialmente, o Presidente da República deverá comunicar ao Presidente do Senado Federal os **motivos do veto** no prazo de **48** horas. Poderá o Presidente da República vetar o projeto de lei se entendê-lo **inconstitucional** (veto jurídico), ou **contrário ao interesse público** (veto político);

■ **características do veto:** o veto é sempre **expresso**, conforme visto. Assim, não existe veto tácito, devendo ser **motivado** e por **escrito**. O veto é sempre **supressivo**, não podendo adicionar. Além disso, o veto é **superável** ou **relativo**, pois poderá ser “derrubado” pelo Parlamento. Podemos afirmar, também, que o veto é **irretratável**, pois, vetando e encaminhando os motivos para o Senado Federal, o Presidente da República não poderá retratar-se;

■ **veto sem motivação:** se o Presidente da República simplesmente vetar, sem explicar os motivos de seu ato, estaremos diante da **inexistência** do veto, portanto, o veto sem motivação expressa produzirá os mesmos

efeitos da sanção (no caso, tácita);

■ **silêncio do Presidente da República:** conforme vimos, recebido o projeto de lei e quedando-se inerte, o silêncio do Presidente importará sanção, ou seja, estaremos diante da chamada **sanção tácita**.

Sancionado o projeto de lei, passará ele para a próxima fase, da **promulgação e publicação**.

Existindo **veto**, este será, **necessariamente**, apreciado em **sessão conjunta** da Câmara e do Senado, dentro de **30 dias** a contar de seu recebimento. ⁸⁸ Pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores, em **votação ostensiva** (votação pública, ou seja, voto “aberto”), o veto poderá ser rejeitado (afastado), produzindo os mesmos efeitos que a sanção (art. 66, § 4.º, da CF/88). (Lembramos que a **EC n. 76/2013** aboliu a votação secreta para essa hipótese).

Sendo *derrubado o veto*, a lei deverá ser enviada ao Presidente da República para promulgação dentro do prazo de 48 horas. Se este não o fizer, caberá ao Presidente do Senado a promulgação, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo (art. 66, §§ 5.º e 7.º, da CF/88). Aqui, o texto não prevê alternativa. Reforçando o comando, a regra diz que **caberá** ao Vice-Presidente do Senado **fazê-lo**.

Na hipótese de o *veto* ser *mantido*, o projeto será arquivado, aplicando-se a regra contida no art. 67, que consagra o **princípio da irrepetibilidade** (cf. *item 9.13.3.7.2*).

■ **9.13.4.2.3. Os vetos devem ser apreciados na ordem cronológica de sua comunicação ao Congresso Nacional? (MS 31.816 — “royalties” do pré-sal)**

Questão interessante diz respeito à obrigatoriedade de análise dos vetos em sua ordem cronológica de comunicação ao Congresso Nacional.

Não há dúvida, e já sinalizamos, de que a **análise** do veto é **obrigatória** pelo Congresso Nacional, de acordo com a literalidade do art. 66, § 4.º, da CF/88.

A **dúvida** surge quanto ao Parlamento ter discricionariedade para “escolher” a

matéria que lhe seja mais conveniente, lembrando que o art. 66, § 6.º, estabelece que, esgotado o prazo de 30 dias para análise do veto sem deliberação, **será colocado na ordem do dia da sessão imediata**, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

Para responder a essa questão, vamos analisar o caso concreto envolvendo o julgamento dos **MS 31.816** e **31.814**, impetrados no STF em 13.12.2012 por parlamentares federais contra o ato da Mesa Diretora do Congresso Nacional, que, acolhendo *requerimento conjunto de urgência n. 12/2012*, tornou iminente a possibilidade de apreciação do *veto parcial n. 38/2012*, que foi apostado pela Presidente da República ao *Projeto de Lei n. 2.565/2011* e que veio a ser convertido na **Lei n. 12.734/2012**.

Referido ato normativo determina novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos *royalties* e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, buscando, ainda, aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha.

Alegava-se violação à regra da Constituição que fixa o prazo de 30 dias para a apreciação, bem como, em sugerido “estelionato regimental”, afronta aos arts. 104⁸⁹ e 105⁹⁰ do *Regimento Interno do Congresso Nacional* (Regimento Comum: Resolução n. 1/70-CN).

No primeiro caso, como existiam mais de 3.000 vetos para serem apreciados, concordamos com a tese, entendendo haver afronta à ordem de apresentação, pois a Constituição estabeleceu que o primeiro veto desse volume acumulado, ainda pendente, deveria ser apreciado em 30 dias, sob pena de ser colocado na ordem do dia, sobrestadas as demais proposições.

No segundo argumento, a análise do veto em relação à nova forma de distribuição dos *royalties* violaria a regra regimental por não ter sido constituída comissão mista de Deputados e Senadores para elaborar relatório sobre o veto presidencial.

Em **17.12.2012**, o Min. Luiz Fux concedeu, **monocraticamente**, liminar, determinando à Mesa Diretora do Congresso Nacional que se abstivesse de

deliberar acerca do veto parcial n. 38/2012 antes que se procedesse à análise de todos os vetos pendentes (mais de 3.000, alguns sem apreciação há mais de 10 anos!), com prazo expirado até a data daquela decisão, em **ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação**, observadas as regras regimentais pertinentes.

Referida decisão, “ante a manifesta contrariedade ao **Estado de Direito** (art. 1.º, *caput*, da CF/88) e à proteção das **minorias parlamentares**”, flexibilizava a jurisprudência do STF, que não admite o controle judicial de questões *interna corporis*.

Contra a liminar concedida pelo Min. Fux, foi interposto **agravo regimental**, julgado em **27.02.2013** pelo Plenário, que, por 6 x 4, cassou-a nos termos da divergência aberta pelo Min. Teori Zavascki. Assim, permitiu-se ao Congresso Nacional, **pelo menos por enquanto**, analisar os vetos de acordo com a sua liberdade política e conveniência. O Min. Lewandowski destacou o denominado **“poder de agenda”**, no sentido de se assegurar ao Congresso Nacional a autonomia para escolher as matérias que considere relevantes do ponto de vista político, social, cultural, econômico e jurídico para o País.

Tendo em vista a apreciação pelo Congresso Nacional do veto, rejeitando-o, referido mandado de segurança, que buscava impedir a violação da ordem de apreciação, perdeu o seu objeto e, assim, nos termos do art. 21, IX, do *RISTF*, foi julgado **prejudicado**.

Deixamos consignado que, em nosso entender, a regra da Constituição é firme e determina a apreciação do veto em 30 dias, sob pena de sobrestamento das demais proposições (art. 66, §§ 4.º e 6.º). Não se pode esvaziar essa regra clara e extremamente importante. O Congresso, mais uma vez, criou nefasto e inconcebível **“costume inconstitucional”** de não apreciar os vetos, alguns, conforme visto, há mais de 10 anos aguardando análise.

Ao julgar prejudicado o mandado de segurança, perdeu o STF a oportunidade de adotar o mesmo entendimento firmado na **ADI 4.029** (cf. *item 9.14.4.3*), qual seja, modulando os efeitos da decisão, a partir de sua decisão de mérito, de modo enérgico, determinar a obrigatoriedade de apreciação dos vetos no prazo

improrrogável de 30 dias, sob pena de sobrestamento das demais proposições.

■ **9.13.4.2.4. Procedimento de apreciação dos vetos presidenciais (Res. n. 1/2015-CN)**

O contexto da aprovação da **Res. n. 1/2015** (DOU, de 12.03.2015), que **altera o procedimento de apreciação dos vetos presidenciais** ao modificar o *Regimento Comum do Congresso Nacional* (Res. n. 1/70), foi marcado pela necessidade de regras mais efetivas e céleres.

Conforme observou o então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, “a modernidade, a racionalidade e a própria sociedade não aceitam mais métodos jurássicos de votação de vetos, com sessões que duram até 19 horas, como já aconteceu. O tumulto passa a ser uma opção política e o Congresso não pode ficar exposto a isso” (*Notícias CD*, 10.02.2015 — 21h29).

Além da modernização e celeridade do procedimento, a alteração buscou adequar o processo de análise às regras introduzidas pela EC n. 76/2013, que definiu a votação aberta (ostensiva), nos termos do art. 66, § 4.º, CF/88.

Entre as regras contidas no regramento, destacamos:

■ **votação nominal e apuração eletrônica:** a votação do veto será **nominal** e ocorrerá por meio de cédula com identificação do parlamentar e que permita a **apuração eletrônica**, da qual constarão todos os vetos incluídos na Ordem do Dia, agrupados por projeto. Inegavelmente, o modelo eletrônico é muito mais eficiente do que as cédulas de papel;

■ **destaques individuais ou conexos e apreciação eletrônica:** até o início da Ordem do Dia, poderá ser apresentado destaque de dispositivos individuais ou conexos para apreciação no painel eletrônico, a requerimento de líderes, que independerá de aprovação pelo Plenário, observados rígida proporcionalidade e importantes limites fixados na referida Resolução. Intimidam-se, assim, as combatidas manobras de obstrução;

■ **discussão em globo:** além de agilizar a votação, a nova regra **limita o tempo de discussão das matérias**, o que, também, busca eliminar as manobras políticas no sentido de se adiar o enfrentamento de temas

polêmicos.

■ 9.13.4.2.5. Regras específicas sobre o veto

■ **Riders:** a figura dos *riders* surgiu quando não havia o instituto do veto parcial. Notadamente nas **leis orçamentárias**, os parlamentares faziam inserir matérias impertinentes, muitas de interesses particulares e sem qualquer relação com as finanças. Assim, como se tinha que aprovar as leis orçamentárias, os *riders*, ou seja, essas “**caudas orçamentárias**” ou “**pingentes**” eram aprovados, sem a possibilidade de excluí-los, já que não havia o veto parcial.

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a grande *virtude* do *veto parcial* é “... permitir separar o joio do trigo, ou seja, excluir da lei o inconveniente sem fulminar todo o texto”.

Contudo, continua, quando não havia veto parcial nos regimes, especialmente os presidencialistas, “... surgiu a prática condenável de os parlamentares inserirem nos projetos de orçamento **disposições parasitárias**, muitas vezes sem nenhuma relação com as finanças públicas, disposições que seriam vetadas se objeto de proposições isoladas”.⁹¹

Portanto, o **veto parcial** surge como indispensável **técnica** para a **superação** dos inconvenientes *riders*.

No Brasil, durante o Império, prevaleceu o entendimento de aceitação apenas do veto total e, assim, situações impertinentes de *riders* nas leis orçamentárias. Em âmbito federal, o **veto parcial** veio a ser introduzido apenas pela **EC n. 1/26**, lembrando que alguns Estados, como o da Bahia, já o previam um pouco antes em suas Constituições estaduais.

■ **pocket veto:** estamos diante daquilo que a doutrina denominou **veto absoluto**. Segundo José Afonso da Silva, “sua utilização impede que se alcance a conclusão da medida proposta, como aquele dos tribunos da plebe da Roma antiga. Hoje, está em desuso, mas existe no *Conselho de Segurança*

da ONU — trata-se do já referido *pocket veto* nos EUA. Vetada absolutamente a matéria, não comporta mais discussão, valendo como rejeição definitiva pelo tempo constitucionalmente estipulado. A matéria só poderá ser objeto de deliberação através de nova iniciativa, verificados os requisitos para que essa possa ocorrer”. [92](#)

O **veto absoluto** caracterizava-se como um fortalecimento demasiado do Executivo e, assim, verdadeiro instrumento de defesa, já que, ao vetar o projeto, estando o Parlamento em recesso, o projeto não seria devolvido e, então, terminaria no “bolso” do Executivo.

Pocket, do inglês, significa “bolso”. Assim, é o “veto de bolso”, no sentido de não se conseguir analisá-lo (já que ele ficaria “embolsado”, por impossibilidade de análise pelo Parlamento).

O direito brasileiro **não adotou** o *pocket veto*. Conforme visto, todo veto deverá, **necessariamente**, ser analisado pelo Parlamento, inclusive com previsão do prazo de 30 dias e, esgotado sem apreciação esse prazo, a sua colocação na ordem do dia da sessão imediata, sobrestando-se as demais proposições, até sua votação final (art. 66, §§ 4.º e 6.º).

Ainda, a ausência de sanção também não significará o “engavetamento” do projeto, visto que o silêncio do Presidente não caducará o projeto, mas, de maneira bastante adequada, importará sanção.

■ 9.13.5. Fase complementar — promulgação e publicação

A fase final ou complementar do processo legislativo pode ser bipartida na promulgação e na publicação da lei. Vejamo-las:

■ 9.13.5.1. Promulgação

A promulgação nada mais é que um atestado da existência válida da lei e de sua executoriedade. Apesar de ainda não estar em vigor e não ser eficaz, pelo ato da promulgação certifica-se o nascimento da lei. José Afonso da Silva aponta

que “o ato de promulgação tem, assim, como conteúdo a presunção de que a lei promulgada é válida, executória e potencialmente obrigatória”.⁹³

Indagamos: o que se promulga, a lei ou o projeto de lei? Seguindo os ensinamentos de José Afonso da Silva, o que se promulga e publica é a **lei**, ou seja, no momento da promulgação o projeto de lei já se transformou em lei. Apesar de alguns entendimentos em contrário, para as provas objetivas dos concursos, adotar o posicionamento de que o projeto de lei vira lei com a **sanção** presidencial ou com a **derrubada do veto** pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, nos termos do art. 66, § 4.º.

Tanto é que o art. 66, § 7.º, fala, expressamente, em **promulgação** da **lei**, e não do projeto de lei.

Em regra, então, a lei deverá ser promulgada pelo Presidente da República. Se no prazo de 48 horas não houver promulgação, nas hipóteses do art. 66, §§ 3.º (sanção tácita) e 5.º (derrubada do veto pelo Congresso), a lei será promulgada pelo Presidente do Senado Federal e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado Federal fazê-lo, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade (art. 66, § 7.º).

■ 9.13.5.2. **Publicação**

Promulgada a lei, deverá ser publicada, ato pelo qual se levará ao conhecimento de todos o conteúdo da inovação legislativa. A publicação implementa-se pela inserção do texto da lei no *Diário Oficial*, devendo ser determinada por quem a promulgou.

Com a publicação, tem-se o estabelecimento do momento em que o cumprimento da lei deverá ser exigido.

Como regra geral, a lei começa a vigorar em todo o País **45 dias** depois de oficialmente publicada (art. 1.º, *caput*, da *LINDB — Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro*).⁹⁴ Havendo disposição expressa em contrário, prevalecerá sobre a regra geral (ex.: “Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”).

Nos **Estados estrangeiros**, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia-se **3 meses** depois de oficialmente publicada.

Algumas exceções à regra geral também foram previstas na Constituição nos arts. 150, III, “b”, e 195, § 6.º.

O período que vai da publicação da lei à sua vigência chama-se ***vacatio legis***.

Finalmente, grande importância deve ser atribuída ao ato da publicação, no sentido de que ninguém poderá escusar-se de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. A publicação enseja, portanto, a presunção de conhecimento da lei por todos (art. 3.º da LINDB).

■ 9.14. ESPÉCIES NORMATIVAS

Como pudemos perceber no início deste capítulo, o processo legislativo compreenderá a elaboração das seguintes espécies normativas: **emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções**.

Importante notar a inexistência de hierarquia entre as espécies normativas, com exceção das emendas constitucionais, que têm a capacidade de produzir normas de caráter constitucional, como veremos.

Nesse sentido é que cada espécie normativa atuará dentro de sua parcela de competência. Por exemplo, se houver atuação de lei ordinária em campo reservado à lei complementar, estaremos diante de invasão de competência, surgindo, então, um vício formal, caracterizador da inconstitucionalidade.

Apesar disso, o professor Michel Temer adverte que existe, de fato, um **escalonamento de normas**, chegando a surgir, em determinadas situações, uma verdadeira relação hierárquica. Isso não se observa em relação às espécies normativas apontadas, mas pode ser verificado nos exemplos pelo autor lembrados: “A lei se submete à Constituição, o regulamento se submete à lei, a instrução do Ministro se submete ao decreto, a resolução do Secretário de Estado se submete ao decreto do Governador, a portaria do chefe de seção se submete à resolução secretarial”. [95](#)

Vejamos cada uma das espécies normativas apontadas no art. 59 da CF/88.

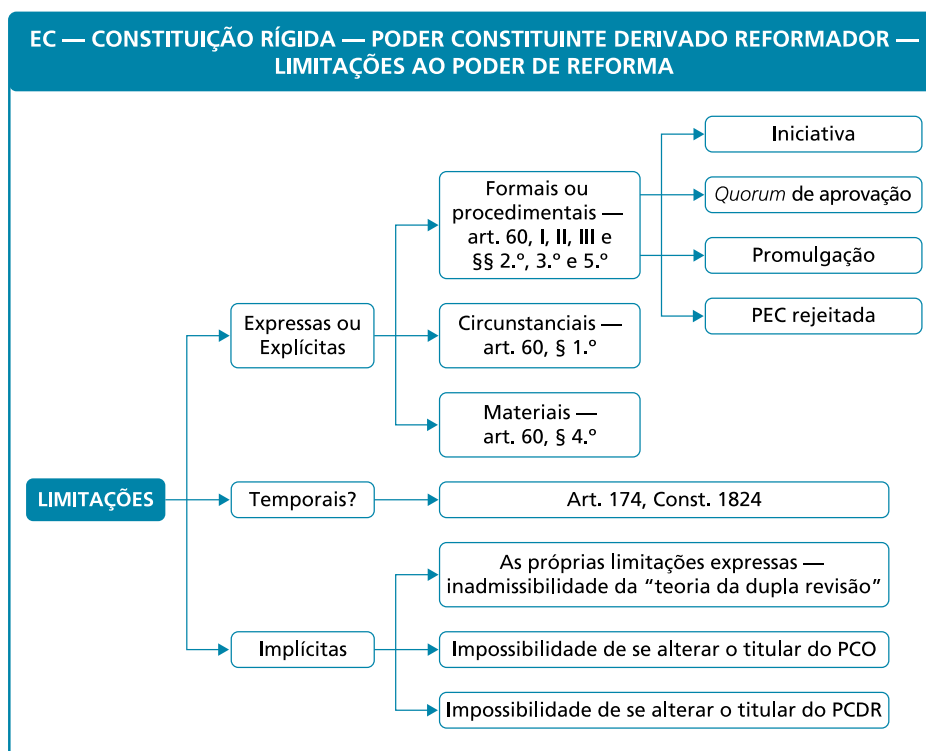
■ 9.14.1. Emenda constitucional

Quando estudamos a teoria do **poder constituinte**, verificamos que as **emendas constitucionais** são fruto do trabalho do *poder constituinte derivado reformador*, por meio do qual se altera o trabalho do poder constituinte originário, pelo acréscimo, modificação ou supressão de normas.

Ao contrário do constituinte originário, que é juridicamente ilimitado, o poder constituinte derivado é condicionado, submetendo-se a algumas limitações, expressamente previstas, ou decorrentes do sistema. Trata-se das limitações **expressas** ou **explícitas** (*formais* ou *procedimentais*, *circunstanciais* e *materiais*) e das **implícitas**.

Assim, o “produto” da PEC, isto é, a matéria introduzida, se houver perfeita adequação aos limites indicados, incorporar-se-á ao texto originário, tendo, portanto, *força normativa de Constituição*.

O veículo, contudo, a PEC aprovada, o instrumento para essa modificação, que se concretiza em uma *emenda à Constituição*, analisada sob o aspecto formal, poderá ser confrontada perante a CF/88.



■ 9.14.1.1. *Limitações formais ou procedimentais (art. 60, I, II, III, e §§ 2.º, 3.º e 5.º)*

■ **Iniciativa (art. 60, I, II e III):** trata-se de **iniciativa privativa** e **concorrente** para alteração da Constituição. Havendo proposta de emenda por qualquer pessoa diversa daquelas taxativamente enumeradas, estaremos diante de vício formal subjetivo, caracterizador da inconstitucionalidade. Nesse sentido é que a CF só poderá ser emendada mediante proposta:

■ de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

■ do Presidente da República;

■ de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação (no caso, as Assembleias Legislativas dos 26 Estados-Membros, mas incluindo-se, também, a Câmara Legislativa do Distrito Federal), manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros.

■ **Quorum de aprovação (art. 60, § 2.º):** a proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **2 turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **3/5** dos votos dos respectivos membros. Diferente é o processo legislativo de formação da lei complementar e da lei ordinária, que deverá ser discutido e votado em um único turno de votação (art. 65, *caput*), tendo por *quorum* a maioria absoluta (art. 69) e a maioria relativa (art. 47), respectivamente. [96](#)

No tocante ao processo legislativo, interessante notar que o texto aprovado por uma Casa não pode ser modificado pela outra sem que a matéria volte para a apreciação da Casa iniciadora. O Congresso Nacional tem utilizado a técnica da PEC Paralela, ou seja, a parte da PEC que não foi modificada é promulgada e a parte modificada volta para reanálise, e como se fosse uma nova EC, para a Casa iniciadora. A não observância desse requisito formal caracterizará o vício de inconstitucionalidade. Para se ter um importante exemplo, destacamos o art. 39, *caput*, declarado inconstitucional (com efeito *ex nunc*) em sede de liminar pelo STF:

“Em conclusão de julgamento, o Tribunal deferiu parcialmente medida liminar em ação direta ajuizada (...) para suspender a vigência do art. 39, *caput*, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/98 (...), mantida sua redação original, que dispõe sobre a instituição do **regime jurídico único dos servidores públicos** — v. *Informativos* 243, 249, 274 e 420. Entendeu-se caracterizada a aparente violação ao § 2.º do art. 60 da CF (...), uma vez que o Plenário da Câmara dos Deputados mantivera, em primeiro turno, a redação original do *caput* do art. 39, e a comissão especial, incumbida de dar nova redação à proposta de emenda constitucional, suprimira o dispositivo, colocando, em seu lugar, a norma relativa ao § 2.º, que havia sido aprovada em primeiro turno. Esclareceu-se que a decisão terá efeitos *ex nunc*, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, que indeferiam a liminar...” (ADI 2.135-MC, Rel. p/ o acórdão Min. Ellen Gracie, j. 02.08.2007, *Inf.* 474/STF — **Matéria pendente de apreciação**).

■ **Promulgação (art. 60, § 3.º):** outra imposição formal é que a promulgação da emenda seja realizada pelas **Mesas da Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal**, com o seu respectivo **número de ordem**. O número de ordem nada mais é do que o numeral indicativo da quantidade de vezes que a Constituição foi alterada (pelo poder constituinte derivado) desde a sua promulgação. Lembramos que, iniciado o processo de alteração do texto constitucional através de emenda, discutido, votado e aprovado, em cada casa, em **2** turnos de votação, o projeto será encaminhado diretamente para promulgação, **inexistindo sanção ou veto presidencial**. Após promulgada, o Congresso Nacional publica a emenda constitucional.

■ **Proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada (art. 60, § 5.º):** a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova apresentação na mesma sessão legislativa. Trata-se de regra diferente da prevista para as leis complementares e ordinárias, em relação às quais é permitido o oferecimento de novo projeto de lei (quando rejeitado) na mesma sessão legislativa, mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas do Congresso (art. 67).

■ **9.14.1.2. Limitações circunstanciais (art. 60, § 1.º)**

Em determinadas circunstâncias, o constituinte originário vedou a alteração do texto original, em decorrência da gravidade e anormalidade institucionais. Nesses termos, a CF não poderá ser emendada na vigência de:

- intervenção federal;
- estado de defesa;
- estado de sítio.

■ **9.14.1.3. Limitações materiais (art. 60, § 4.º)**

O poder constituinte originário também estabeleceu algumas vedações materiais, ou seja, definiu um núcleo *intangível*, comumente chamado pela doutrina de **cláusulas pétreas**. Nesse sentido (e inovando o disposto no art. 50, § 1.º, da Constituição de 1967, que previa como “cláusulas pétreas” apenas a *Federação* e a *República*), não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- a forma federativa de Estado;
- o voto direto, secreto, universal e periódico;
- a separação dos Poderes;
- os direitos e garantias individuais.

A) Reforma da Previdência

Nesse sentido, a **Reforma da Previdência** (EC n. 41/2003) foi amplamente discutida, em especial, dentre vários pontos, a mudança nas regras de transição para a aposentadoria (discutida na ADI 3.104, proposta pela CONAMP) e a taxação dos inativos e pensionistas (discutida na ADI 3.105, proposta pela CONAMP, e na ADI 3.099, proposta pelo PDT).

De acordo com o relatado em *Notícias STF* (02.01.2004), “na ADI 3.104, a Conamp diz que na reforma da previdência aprovada em 1998 foram criadas **regras de transição** que passaram a constituir **direito adquirido** e, por isso, não podem ser alteradas. A entidade explica, na ação, que a reforma de 1998 não estabeleceu regime jurídico objetivo aplicável a todos os servidores públicos, mas assegurou direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico de determinada classe de servidores públicos. Assim, assegura, a EC 41/03 ‘não poderia, como fez, retroagir para alterar-lhe o conteúdo, de modo a prejudicar aquele direito adquirido e impor situação jurídica mais gravosa aos seus titulares’. A nova emenda estabeleceu um redutor de até 5% no valor do benefício por ano de antecipação para quem se aposentar antes da idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Na ação contra a taxação dos inativos e pensionistas (ADI n. 3.105), a Conamp diz que os servidores aposentados têm garantido o direito de não pagar contribuição. Afirma, ainda,

que esse direito foi garantido na reforma de 1998 que instituiu o caráter contributivo no regime previdenciário”.

Como é do conhecimento de todos, já houve, pelo STF, apreciação dos pontos controvertidos da *Reforma da Previdência*.

Conforme noticiado, “por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a cobrança de inativos e pensionistas instituída no artigo 4.º da Emenda Constitucional (EC) 41/2003. Votaram pela cobrança os Ministros Cezar Peluso, Eros Grau, Gilmar Mendes, Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim. Já a Ministra relatora Ellen Gracie e os Ministros Carlos Ayres Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello votaram contra a cobrança. Os ministros que decidiram pela constitucionalidade da cobrança seguiram o voto do Ministro Cezar Peluso, que fez ressalva quanto à instituição de alíquotas diferentes (incisos I e II do parágrafo único do artigo 4.º da EC 41/2003) para a contribuição de servidores dos Estados, Municípios e Distrito Federal (50%) e de servidores da União (60%). Para ele, o tratamento diferenciado é inconstitucional por ferir o princípio da igualdade. O resultado prático da decisão do Supremo é que, para todos os inativos e pensionistas, sejam eles federais ou estaduais, a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a parcela dos proventos e pensões que exceder o teto estabelecido no artigo 5.º da EC 41/2003. O dispositivo fixa em R\$ 2.400 o teto para incidência da contribuição, devendo esse valor ser atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social...”.

E mais, “ao votar pela constitucionalidade da contribuição, Peluso argumentou que o sistema previdenciário vigente no País não é regido por normas de Direito privado, mas sim pelo Direito público. ‘O regime previdenciário público tem por escopo garantir condições de subsistência, independência e dignidade pessoais ao servidor idoso, mediante o pagamento de proventos de aposentadoria durante a velhice, e, conforme o artigo 195 da Constituição, deve ser custeado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, o que bem poderia chamar-se de ‘princípio estrutural da solidariedade’, afirmou o Ministro” (Notícias STF, 18.08.2004 — 21h57. Cf., também, *Inf. 357/STF*. A

íntegra do voto do Ministro Peluso pode ser encontrada no site do STF, *Notícias*, 24.08.2004 — 16h00: <www.stf.gov.br/noticias/imprensa/VotoPelusoInativos.pdf>).

B) Atribuição de competência estadual para legislar sobre direito penal

De acordo com o art. 22, I, compete privativamente à União legislar sobre **direito penal**. Portanto, eventual lei estadual, distrital ou municipal nesse sentido seria inconstitucional (vício formal).

A única exceção que existe atualmente, nos termos da Constituição, dá-se no caso de a União, por meio de **lei complementar**, autorizar os Estados a legislar sobre direito penal. Contudo, na hipótese, a autorização deverá restringir-se a **questões específicas** (art. 22, parágrafo único).

Como bem anotaram Estefam e Gonçalves⁹⁷, valendo-se das lições de *Luiz Vicente Cernicchiaro* e *Paulo José da Costa*, diante de autorização expressa da União por lei complementar, os Estados e o Distrito Federal, ao exercerem a atribuição normativa, estão **proibidos de “... disciplinar temas fundamentais de Direito Penal**, notadamente aqueles ligados à Parte Geral. A lei local, ainda, deverá manter-se em **harmonia com a federal**, estabelecendo-se entre ambas uma relação de regra e exceção, cumprindo que esta seja plenamente justificada diante de **peculiaridades regionais**. Os Estados e o Distrito Federal poderão apenas, a pretexto de regular temas específicos, definir condutas como infrações penais e impor-lhes a respectiva pena, **sem jamais afrontar a lei federal**, inovando apenas no que se refere às suas **particularidades**”

Lembrando que ainda não se fez uso dessa prerrogativa, os autores destacam interessante exemplo trazido por *Cernicchiaro*: “na década de 1980, ocorreu, em Goiás, a contaminação de pessoas com material radioativo (o Césio-137), resultando na necessidade de armazenamento e enterramento do ‘lixo atômico’ encontrado. Esse fato, de efeito local, poderia ser objeto da legislação estadual de cunho penal, visando a eliminar novos riscos de contato humano”.

Finalmente, surge a pergunta: EC que transfira a competência da União para os Estados para legislar sobre direito penal viola cláusula pétrea? O tema ainda não foi discutido pelo STF, mas entendemos que seria perfeitamente possível.

Em relação à forma federativa, a nosso ver, não tenderia a aboli-la, mas a fortalecê-la, já que aumentaria a competência estadual. A questão, agora de natureza política e social — e não mais técnica —, seria a análise da conveniência social, especialmente pela dificuldade de se ter a informação sobre os diversos tipos penais que poderiam surgir (*estamos amadurecendo esse assunto e aguardarmos críticas e sugestões*).

C) Redução da maioria penal de 18 para 16 anos (art. 228 da CF/88)

Esse tema foi enfrentado neste estudo no *item 19.9.15* e concluímos ser **possível**, sim, a redução da maioria penal de 18 para 16 anos, uma vez que o texto apenas não admite a proposta de emenda (PEC) que tenda a abolir o *direito e garantia individual*. Isso não significa, como já interpretou o STF, que a matéria não possa ser modificada. O que não se admite é reforma que tenda a abolir, repita-se, tais direitos, dentro de um parâmetro de razoabilidade.

Reduzindo de 18 para 16 anos o direito à imputabilidade, tido como garantia fundamental, ele não deixará de existir, e eventual modificação encontrará, inclusive, coerência com a responsabilidade política de poder exercer a capacidade eleitoral ativa (direito de eleger) a partir dos 16 anos.

■ 9.14.1.4. Limitações temporais?

As **limitações temporais**, na história constitucional brasileira, foram previstas apenas na Constituição do Império, de 1824, **não se verificando nas que se seguiram**. Trata-se de previsão de prazo durante o qual fica **vedada** qualquer alteração da Constituição. O exemplo único é o art. 174 da citada Constituição Política do Império, que permitia a reforma da Constituição somente após 4 anos de sua vigência.

Assim, **não** há **limitação expressa temporal** prevista na CF/88. Convém lembrar que a regra do art. 3.º do ADCT (poder constituinte derivado revisor), que determinou a revisão constitucional após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral, **não configurou nenhuma limitação**

temporal ao poder de reforma, mas apenas a **previsão de prazo para a malfeita revisão constitucional já esgotada**. Durante esse período de pelo menos 5 anos, como se sabe, a Constituição, observados os limites já expostos, poderia, como foi (*vide* **ECs ns. 1 a 4**), ser reformada por emendas constitucionais, através da manifestação do poder constituinte derivado reformador.

■ 9.14.1.5. **Limitações implícitas**

Até agora, estudamos as limitações expressas, explicitamente estabelecidas pelo constituinte originário de 1988.

Indagamos, aprofundando a discussão: seria possível, por exemplo, através de emenda constitucional, revogar expressamente o art. 60, § 4.º, I, e, em um segundo momento, dizer que a *forma de Estado* não é mais a **Federação**, passando o Brasil a se constituir em um **Estado unitário**? Trata-se da teoria da **dupla revisão**, defendida por *Jorge Miranda*, segundo a qual em um primeiro momento se revoga uma cláusula pétrea, para, em seguida, modificar aquilo que a cláusula pétrea protegia. [98](#)

Apesar de o entendimento exposto ser defendido por renomados juristas estrangeiros e pátrios, como o Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, [99](#) orientamos para as provas de concursos públicos o posicionamento adotado pela grande maioria dos doutrinadores nacionais, estabelecendo a total **impossibilidade** da teoria da **dupla revisão**, na medida em que existem **limitações implícitas**, decorrentes do sistema, conforme expõe Michel Temer: “as *implícitas* são as que dizem respeito à forma de criação de norma constitucional bem como as que impedem a pura e simples supressão dos dispositivos atinentes à intocabilidade dos temas já elencados (art. 60, § 4.º, da CF)”. [100](#)

Portanto, as **limitações expressas** já apontadas caracterizam-se como a primeira **limitação implícita** ou **inerente**.

Outras duas limitações implícitas apontadas pela doutrina são a

impossibilidade de se alterar tanto o titular do poder constituinte originário como o titular do poder constituinte derivado reformador.

■ 9.14.1.6. *Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e a sua equivalência com as emendas constitucionais — EC n. 45/2004*

Nos termos do § 3.º do art. 5.º, introduzido pela EC n. 45/2004, e esse tema será aprofundado no item 9.14.5.2.2, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Como exemplo, destacamos o Decreto Legislativo n. 186, de 09.07.2008, que aprova o texto da *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* e de seu *Protocolo Facultativo*, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgada pelo Decreto n. 6.949, de 25.08.2009, tendo sido, assim, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de norma constitucional.

■ 9.14.2. Lei complementar e lei ordinária

■ 9.14.2.1. *Semelhanças*

O processo legislativo de constituição das leis complementares e ordinárias foi exaustivamente analisado quando expusemos a teoria do processo legislativo, constituindo-se, basicamente, em três fases distintas, a saber: fase de iniciativa (deflagra-se o processo legislativo); fase constitutiva (em que ocorre a *deliberação parlamentar*, pela discussão e votação, bem como a *deliberação executiva*, manifestando-se o Chefe do Executivo pela sanção ou veto) e a fase complementar (promulgação e publicação). Como regra geral, por meio das leis editar-se-ão normas gerais e abstratas, regulamentando as normas

constitucionais.

■ 9.14.2.2. *Diferenças*

Existem duas grandes diferenças entre a lei complementar e a ordinária, uma do ponto de vista material e outra do ponto de vista formal.

■ 9.14.2.2.1. *Aspecto material*

As hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de **lei complementar** estão **taxativamente** previstas no texto Maior. Sempre que o constituinte originário (ou até mesmo o derivado reformador, conforme previsto, por exemplo, nos arts. 146-A e 202, assim como poderia ter sido trazido pelo derivado revisor) quiser que determinada matéria seja regulamentada por lei complementar, expressamente, assim o requererá.

As hipóteses que serão regulamentadas por lei complementar foram **predeterminadas**, conforme se observa pelo quadro comparativo no final deste capítulo, onde reunimos todas as hipóteses previstas na CF/88. Desde já, como exemplos, citamos os arts. 7.º, I; 14, § 9.º; 18, §§ 2.º, 3.º e 4.º; 21, IV; 22, parágrafo único; 23, parágrafo único; 25, § 3.º...

Em relação às **leis ordinárias**, o campo material por elas ocupado é **residual**, ou seja, tudo o que não for regulamentado por lei complementar, decreto legislativo (art. 49 — matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional) e resoluções (arts. 51 e 52 — matérias de competência privativa, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal).

■ 9.14.2.2.2. *Aspecto formal*

No tocante ao **aspecto formal**, a grande diferença entre lei complementar e lei ordinária está no **quorum de aprovação** do respectivo projeto de lei. Enquanto a **lei complementar** é aprovada pelo *quorum* de **maioria absoluta**,

as **leis ordinárias** o serão pelo *quorum* de **maioria simples** ou **relativa**.[101](#)
Então vejamos:

■ LEI COMPLEMENTAR	■ MAIORIA ABSOLUTA (art. 69)
■ LEI ORDINÁRIA	■ MAIORIA SIMPLES ou RELATIVA (art. 47)

Resta saber qual a diferença entre maioria absoluta e maioria simples. Nos dois casos, busca-se a *maioria*, só que, para o *quorum* de **maioria absoluta**, a *maioria* será dos **componentes**, do total de membros integrantes da Casa (sempre um número fixo), enquanto para a **maioria simples** a *maioria* será dos presentes à reunião ou sessão que, naquele dia de votação, compareceram.

Valendo-nos do direito tributário para melhor explicar, fazemos uma analogia: a “*alíquota*” (maioria) será sempre a mesma. O que muda é a “*base de cálculo*”, ou seja: a) **maioria absoluta**: busca-se saber a **maioria** (*alíquota*) dos **componentes** (*base de cálculo*); b) **maioria simples**: busca-se saber a **maioria** (*alíquota*) dos **presentes** (*base de cálculo*).

E como achar a maioria, a “*alíquota*”? A maioria será sempre metade mais um para números pares e o primeiro número inteiro superior à metade para números ímpares.[102](#) Vejamos alguns exemplos:

- $100 \rightarrow 51$ ($100 \div 2 = 50 \rightarrow 50 + 1 = 51$);
- $51 \rightarrow 26$ ($51 \div 2 = 25, 5 \rightarrow$ o primeiro número inteiro superior à metade = 26);
- $50 \rightarrow 26$ (também 26, pois: $50 \div 2 = 25 \rightarrow 25 + 1 = 26$);
- $81 \rightarrow 41$ ($81 \div 2 = 40, 5 \rightarrow$ o primeiro número inteiro superior à metade = 41 $\rightarrow$ obs.: 81 é o número de Senadores da República);[103](#)
- $513 \rightarrow 257$ ($513 \div 2 = 256, 5 \rightarrow$ o primeiro número inteiro superior à metade = 257 $\rightarrow$ obs.: 513 é o número de Deputados Federais, de acordo

com o art. 1.º da Lei Complementar n. 78, de 30.12.1993).

Para finalizar devemos lembrar uma pequena regra prevista no art. 47, que diz: “salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria** dos votos, presente a **maioria absoluta de seus membros**”. Trata-se do *quorum* para a aprovação da **lei ordinária**, qual seja, o da **maioria simples**. No entanto, deverá estar presente na sessão de votação, pelo menos, a **maioria absoluta** dos membros. Trata-se do *quorum* de **instalação da sessão de votação**. Presente o *quorum* de instalação da sessão (que é de maioria absoluta), aí sim poder-se-á realizar a votação, que se dará pelo *quorum* da maioria simples, vale dizer, dos presentes àquela sessão.

Exemplificando: imaginem que em determinada Casa existam 100 Deputados (número dos componentes). Deve-se votar um projeto de lei ordinária, cujo *quorum* é o da maioria simples. Assim, para iniciar a votação, de acordo com o art. 47, deve estar presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros (*quorum* de instalação da sessão). A votação só começa se estiverem presentes, no exemplo criado, 51 Deputados. Imaginem que naquele dia compareceram 60. Podemos iniciar a votação? Sim, já que presente a maioria absoluta dos membros (pelo menos 51). Qual será o *quorum* de aprovação se comparecerem 60 àquela sessão? Ter-se-á aprovação se pelo menos 31 disserem sim!

Então, podemos afirmar que o *quorum* de **votação** (ou, melhor dizendo, de **instalação da sessão de votação**) é o **mesmo** tanto para a **lei ordinária** como para a **lei complementar**. A grande diferença (além do aspecto material já estudado), analisando o aspecto **formal**, reside no *quorum* de **aprovação**: a) lei ordinária — **maioria simples** (no exemplo 31); b) lei complementar — **maioria absoluta** (no exemplo 51). Vejamos o quadro analisando um parlamento hipotético com **100 componentes**, para aprovação de lei ordinária e complementar, sendo que naquele dia compareceram 60 pessoas:

PARLAMENTO HIPOTÉTICO

(100 componentes. Naquele dia compareceram 60 dos 100)

LEI ORDINÁRIA	LEI COMPLEMENTAR
■ <i>Quorum</i> de instalação da sessão de votação — pelo menos 51 (maioria absoluta) . Como vieram, na hipótese, 60, podemos começar a votar	■ <i>Quorum</i> de instalação da sessão de votação — pelo menos 51 (maioria absoluta) . Como vieram, na hipótese, 60, podemos começar a votar
■ <i>Quorum</i> de aprovação — 31 (maioria simples) . Maioria dos presentes (60)	■ <i>Quorum</i> de aprovação — 51 (maioria absoluta) . Maioria dos componentes (100)

Conforme observou José Afonso da Silva, “a maioria simples pressupõe deliberação única, a prática de um ato simples de homologação, de aprovação, de referendo, de escolha, de sorte que valem os votos positivos ou negativos, não se levando em consideração os votos brancos e as abstenções, nem os votos nulos”. [104](#)

■ 9.14.2.3. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária?

Essa matéria é muito discutida na doutrina, e há opiniões contrárias e fortes argumentos nos dois sentidos. [105](#) Valendo-nos de interessante compilação realizada por Alexandre de Moraes [106](#) concernente aos juristas que entendem haver hierarquia da lei complementar sobre a lei ordinária (e o próprio autor se enquadra nesse grupo), podemos citar Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Haroldo Valadão, Pontes de Miranda, Wilson Accioli, Nelson Sampaio, Geraldo Ataliba, dentre outros. A lei complementar apresenta-se como um *tertium genus*, localizada entre a Constituição e a lei ordinária. A hierarquia se dá em decorrência do *quorum* mais qualificado e das hipóteses taxativas de previsão da lei complementar.

Por outro lado, o autor lembra nomes como os de Celso Bastos, Michel Temer, aos quais acrescentamos Luiz Alberto David Araujo, Vidal Serrano

Nunes Júnior, Leda Pereira Mota, Celso Spitzcovsky, dentre outros, no sentido de inexistir hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, na medida em que ambas encontram o seu **fundamento de validade** na Constituição, existindo, como observou Temer, “âmbitos materiais diversos atribuídos pela Constituição a cada qual destas espécies normativas”. [107](#)

Posicionamo-nos também pela **inexistência de hierarquia entre as duas espécies normativas**, pois admitir isso seria o mesmo que entender que uma lei municipal é hierarquicamente inferior a uma lei federal. Têm-se, na verdade, âmbitos diferenciados de atuação, atribuições diversas, de acordo com as regras definidas na Constituição.

Nessa linha da inexistência de hierarquia entre LC e LO, a EC n. 45/2004, modificando a competência do STF e do STJ, estabeleceu, como nova hipótese de cabimento de *recurso extraordinário*, quando a decisão recorrida “julgar válida lei **local** contestada em face de lei **federal**”. No fundo, percebe-se, também aqui, que o problema é de competência constitucional, e não de hierarquia de normas.

A tendência da jurisprudência do STF era nesse sentido (**inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária**), destacando-se vários **precedentes**: RE 457.884-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.02.2006, *DJ* de 17.03.2006; RE 419.629, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23.05.2006, *DJ* de 30.06.2006; AI 637.299-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.09.2007, *DJ* de 05.10.2007. Cf., também, *Inf. 459/STF*.

Finalmente, o **STF** se posicionou no sentido da **inexistência de hierarquia** entre lei complementar e lei ordinária, o que estudaremos no *item 19.2.5.1*, remetendo o nosso ilustre leitor para o aprofundamento (cf. RE 419.629, 377.457 e 381.964).

■ 9.14.3. Lei delegada

A lei delegada caracteriza-se como exceção ao **princípio da indelegabilidade de atribuições**, na medida em que a sua elaboração é antecedida de delegação

de atribuição do Poder Legislativo ao Executivo, através da chamada delegação *externa corporis*.

Vimos que o Legislativo pode delegar o poder de elaborar as regras tanto internamente, ou seja, para as **Comissões temáticas**, nos termos regimentais e se não houver recurso para o Plenário (art. 58, § 2.º, I), e essa é a denominada **delegação interna corporis**, como também externamente, para outro Poder, e essa será a **delegação externa corporis**, tendo-se como bom exemplo a **lei delegada**.

A espécie normativa em análise será elaborada pelo **Presidente da República**, após prévia solicitação ao Congresso Nacional, delimitando o assunto sobre o qual pretende legislar. Trata-se da primeira fase do processo legislativo de elaboração da lei delegada, denominada **iniciativa solicitadora**.

A solicitação será submetida à apreciação do Congresso Nacional, que, no caso de aprovação, tomará a forma de **resolução** (art. 68, § 2.º), especificando o conteúdo da delegação e os termos de seu exercício.

Lembramos que determinadas matérias não poderão ser delegadas (princípio da indelegabilidade de atribuições). A Constituição, em seu art. 68, § 1.º, veda a delegação:

- de atos da **competência exclusiva** do Congresso Nacional (art. 49);
- dos de **competência privativa** da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (arts. 51 e 52);
- das matérias reservadas à **lei complementar** (ver quadro comparativo no final deste capítulo);
- de **legislação sobre**: I — organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros; II — nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; III — planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Havendo exorbitância nos limites da delegação legislativa (ou seja, caso o Presidente da República elabore a lei delegada além do limite fixado na resolução congressional), caberá ao **Congresso Nacional** sustar o aludido ato normativo,

por meio de **decreto legislativo**, realizando, desta feita, controle repressivo de constitucionalidade (art. 49, V). Em nosso entender, essa sustação opera efeito *ex nunc*, ou seja, a partir de então, especialmente em razão da natureza jurídica normativa do decreto legislativo a ser editado pelo CN. [108](#)

Por meio da resolução, que especificará o conteúdo e os termos de seu exercício, o Congresso Nacional determinará se haverá ou não a apreciação do projeto de lei delegada (elaborada pelo presidente da República) pelo Congresso Nacional. Havendo apreciação, o Congresso Nacional a fará em **votação única**, sendo vedada qualquer emenda (art. 68, § 3.º).

Podemos, então, reconhecer tanto a *delegação típica* como a *delegação atípica*:

■ **delegação típica:** não haverá apreciação pelo Congresso Nacional. Este autoriza a delegação ao Presidente da República, que irá elaborar, promulgar e fazer publicar a lei delegada;

■ **delegação atípica:** nessa hipótese, haverá apreciação pelo Congresso Nacional, em votação única e vedada qualquer emenda. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, nesse caso, temos uma “inversão do processo de elaboração de leis ordinárias”, chegando a afirmar que o Congresso Nacional “sancionará” o projeto elaborado pelo Chefe do Executivo. [109](#)

Concordamos com esta observação já que, na *delegação atípica*, o Presidente é quem elaborará o ato normativo, cabendo ao Congresso Nacional, em análise posterior, aceitá-lo (e, nesse caso, seria a aquiescência política, aproximando-se da ideia de “sanção”) ou rejeitá-lo (o que corresponderia ao “veto”), mas, claro, com todas as particularidades da tramitação do projeto de lei delegada.

Nos dois casos (havendo ou não apreciação do projeto pelo Congresso), entendemos **dispensáveis** a sanção e o veto presidenciais, pois seria ilógico o veto de projeto elaborado pelo próprio Presidente se não vai haver eventual alteração na redação original, já que é “vedada qualquer emenda”.

Elaborada a lei delegada (aprovada, quando solicitada na resolução a apreciação parlamentar — art. 68, § 3.º), o Presidente da República a

promulgará, determinando a sua publicação no órgão oficial.

Importante ressaltar que, mediante resolução, transfere-se apenas, e **temporariamente**, competência para legislar sobre determinadas matérias, **permanecendo** a **titularidade** da aludida competência com o **Legislativo**, que poderá, mesmo tendo havido delegação ao Presidente, legislar sobre a mesma matéria.

Entendemos, também, que, muito embora tenha havido delegação legislativa pelo CN ao Presidente da República, este não estará obrigado a efetivar a elaboração do referido ato normativo, tendo total discricionariedade.

Por fim, constata-se a pouca utilização do instituto da lei delegada pelo Presidente da República,¹¹⁰ tendo em vista tanto o seu poder de iniciativa como, principalmente em termos de “agilidade” e efetividade normativa, a previsão da **medida provisória**. É o nosso próximo item de estudo.

■ 9.14.4. Medida provisória

■ 9.14.4.1. Aspectos iniciais

A medida provisória, prevista no art. 62 da atual Constituição, substituiu o antigo **decreto-lei 111** (art. 74, “b”, c/c os arts. 12 e 13 da Constituição de 1937; arts. 49, V, e 58 da Constituição de 1967 e arts. 46, V, e 55 da Constituição de 1967, na redação dada pela EC n. 1/69), recebendo forte influência dos *decreti-legge* da Constituição italiana, de 27 de dezembro de 1947, cujo art. 77 permite a sua adoção *in casi straordinari di necessità e d’urgenza*.

No entanto, o modelo italiano é bem diverso do brasileiro, já que na Itália o sistema de governo é o **parlamentar**, e o art. 77 da citada Constituição estabelece que o “Governo” (Gabinete, por intermédio do Primeiro-Ministro) adotará o “provimento provisório com força de lei” *sob* sua **responsabilidade política**.

Eis a grande peculiaridade do sistema italiano, muito bem percebida por

Michel Temer, que indaga: o que acontece se a medida provisória não for aprovada pelo Parlamento italiano? “O Gabinete (Governo) cai”, explica o ilustre professor, diferente da nossa Constituição, que “... **não** prevê a **responsabilidade política** do Presidente da República no caso de não aprovação da *medida provisória*”.¹¹² Nesse sentido, inquestionável a sua melhor adequação ao sistema de governo parlamentar.¹¹³

A medida provisória é adotada pelo Presidente da República, por ato **monocrático, unipessoal**, sem a participação do Legislativo, chamado a discuti-la somente em momento posterior, quando já adotada pelo Executivo, com força de lei e produzindo os seus efeitos jurídicos.¹¹⁴

Observa-se, nessa primeira abordagem, que a medida provisória foi estabelecida pela CF/88 com a esperança de corrigir as distorções verificadas no regime militar, que abusava de sua função atípica legiferante por intermédio do decreto-lei.

A experiência brasileira mostrou, porém, a triste alteração do verdadeiro sentido de utilização das medidas provisórias, trazendo insegurança jurídica, verdadeira “ditadura do executivo”, governando por inescrupulosas “penadas”, em situações muitas das vezes pouco urgentes e nada relevantes.¹¹⁵

Nesse sentido, cabe referir que, quando da aprovação da **EC n. 32/2001**, que será comentada a seguir, no período entre 05.10.1988 e 20.09.2001, já havia sido editado e reeditado o assustador número de **6.130** medidas provisórias, chegando algumas delas a levar quase **sete anos** sem aprovação (por exemplo, a **MP n. 2.096/89**, dispondo sobre os títulos da dívida pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, convertida na Lei n. 10.179, de 06.02.2001, tendo por MP originária a de n. 470, de 11.04.1994, que tramitou por longos **2.493 dias**).

Interessante levantamento realizado pelo Senador Romero Jucá relata que, “na questão do rito e na questão da média de dias para a aprovação das medidas provisórias, verificamos que, em 1988, gastavam-se, em média, 38,9 dias para aprovar uma medida provisória. Esse número foi crescendo ao longo dos anos, chegando, em 1998, a 507 dias de tramitação; em 1999, a 438; e, em 2000, a 472 dias”.¹¹⁶

Assim, até o advento da **EC n. 32/2001**, constatava-se a total desvirtuação do instituto da medida provisória, admitindo-se, com o consentimento do STF e do próprio Congresso Nacional, a **reedição das medidas provisórias**, mantendo-se os efeitos de lei a partir da primeira edição, desde que **não** houvesse expressa rejeição pelo Congresso Nacional e fosse dentro do seu antigo prazo de eficácia de 30 dias (**S. 651/STF**).¹¹⁷ Tratava-se de entendimento totalmente contrário ao preceituado no art. 62 da CF/88, por nós refutado na 2.^a edição deste trabalho, acompanhando diversos doutrinadores de renome, porém indicado a ser observado nos concursos públicos em razão do posicionamento do STF.¹¹⁸

Nesse contexto é que, após a sua tramitação por mais de seis longos anos, em **05.09.2001**, foi votada e aprovada, em segundo turno, a **PEC n. 1-B, de 1995** (n. 472/97, na Câmara dos Deputados), com parecer favorável, sob n. 729/01, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (*DSF* de 09.08.2001, fls. 15939-40), tendo sido promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, **em 11.09.2001, a EC n. 32/2001**, trazendo limites à edição das medidas provisórias e entrando em vigor na data de sua publicação — **12.09.2001**.

■ **9.14.4.2. O processo de criação das medidas provisórias de acordo com a EC n. 32/2001**

Nos termos do art. 62, *caput*, da CF/88, em caso de **relevância e urgência**, o **Presidente da República** poderá adotar medidas provisórias com **força de lei**, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Assim, a MP individualiza-se por nascer apenas pela manifestação exclusiva do Chefe do Executivo, que a publica no *DOU*. Vejamos, pois, com atenção, o processo de criação da MP, esquematizando a matéria de acordo com as novas regras fixadas na **EC n. 32/2001**:

- **legitimado para a edição da MP:** o Presidente da República (competência **exclusiva**, marcada por sua **indelegabilidade**, art. 84, XXVI, da CF);¹¹⁹

■ **pressupostos constitucionais:** relevância e urgência. Os requisitos conjugam-se; [120](#)

■ **prazo de duração da MP:** pela nova regra, uma vez adotada a MP pelo **Presidente da República**, ela vigorará pelo prazo de **60 dias**, prorrogável, de acordo com o art. 62, § 7.º, uma vez por igual período (novos 60 dias), contados de sua **publicação** no *Diário Oficial*. Nos termos do art. 62, § 4.º, contudo, referido **prazo** será **suspenso** durante os períodos de **recesso parlamentar**. Para exemplificar, imagine-se que determinada MP tenha sido publicada em 5 de julho de determinado ano. Nessa hipótese, ela produzirá efeitos até 17 de julho, já que, pela nova regra fixada pela **EC n. 50/2006** — que modificou a redação do art. 57, *caput* — em **18 de julho**, inaugura-se o primeiro **recesso parlamentar** (art. 57, *caput*). Suspenso o prazo durante o aludido período de recesso (de 18 a 31 de julho), voltará ele a fluir após o término do recesso parlamentar, qual seja, no exemplo dado, em 1.º de agosto, pelo prazo **restante** (já que se trata de suspensão e não de interrupção de prazo).

Significa um retrocesso, pois, de acordo com a regra anterior, antes do advento da EC n. 32/2001, adotada a MP pelo Presidente da República e estando o Congresso Nacional em recesso, proceder-se-ia à sua convocação extraordinária no prazo de 5 dias. Segundo a nova regra, ao que se percebe, na redação dada ao **art. 62, § 4.º**, acrescentado, o referido prazo fica **suspenso** durante o período de recesso do Congresso Nacional. Em contrapartida, amenizando a falta de previsão expressa de convocação extraordinária para o caso de adoção de MP, a EC n. 32/2001 estabeleceu que, em eventual **convocação extraordinária**, havendo medidas provisórias em vigor na data de sua convocação, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação (art. 57, § 8.º);

■ **prorrogação do prazo da MP por novos 60 dias:** como visto, adotada a MP pelo Presidente da República, ela produzirá efeitos por **60 dias**, devendo ser submetida de imediato ao Congresso Nacional. No entanto, findo esse prazo inicial, contado da data de sua publicação, e não tendo sido encerrada a votação nas duas Casas do Congresso Nacional, o

prazo inicial de 60 dias será **prorrogado** por **novos 60 dias**, uma única vez, totalizando o prazo de **120 dias**, quando então, se não for convertida em lei, a MP **perderá a eficácia desde a sua edição**;

■ **eficácia da MP**: o art. 62, § 3.º, da CF/88 estabelece que as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, **desde a edição**, se não forem convertidas em lei no prazo de **60 dias**, prorrogável, nos termos do § 7.º, uma vez por igual período (**novos 60 dias**), devendo o Congresso Nacional disciplinar, por **decreto legislativo**, as relações jurídicas delas decorrentes; ou seja, não sendo a MP apreciada no referido prazo de 60 dias prorrogáveis por novos 60 dias, ela perderá a sua eficácia desde a sua edição, operando efeitos *ex tunc*, confirmando a sua **efemeridade e precariedade**;

■ **tramitação**: adotada a MP pelo Presidente da República ela será submetida, de imediato, ao Congresso Nacional, cabendo, de acordo com o art. 62, §§ 5.º e 9.º, da CF/88, a uma **comissão mista de Deputados e Senadores** examiná-la e sobre ela emitir parecer, apreciando os seus **aspectos constitucionais** (inclusive os pressupostos de relevância e urgência) e de **mérito**, bem como a sua **adequação financeira e orçamentária** e o cumprimento, pelo Presidente da República, da exigência contida no art. 2.º, § 1.º, da Res. n. 1/2002-CN, qual seja, no dia da publicação da MP no *DOU* ter enviado o seu texto ao Congresso Nacional, **acompanhado da respectiva mensagem e de documento expondo a motivação do ato**. Posteriormente, a MP, com o parecer da comissão mista, passará à apreciação pelo **plenário** de cada uma das Casas. O **processo de votação**, como visto e inovando, será em **sessão separada**, e não mais conjunta, tendo início na **Câmara dos Deputados**, sendo o **Senado Federal** a Casa revisora. O art. 8.º da **Resolução n. 1/2002-CN**, substituindo as regras contidas na Resolução n. 1/89-CN, [121](#) estabeleceu que o plenário de cada uma das Casas decidirá, em **apreciação preliminar**, o atendimento ou não dos **pressupostos constitucionais de relevância e urgência**, bem como a sua **adequação financeira e orçamentária**, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito. Isso porque, se o plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos

constitucionais ou pela inadequação financeira ou orçamentária da medida provisória, esta será arquivada;

■ **regime de urgência constitucional:** o art. 62, § 6.º, da CF/88 dispõe que, se a medida provisória não for apreciada em até **45 dias** contados de sua **publicação**, entrará em **regime de urgência**, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. É de observar que o então Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, anunciou uma nova interpretação a respeito do regime de urgência, orientando que a pauta não fica travada em relação a matérias que não podem, em tese, ser objeto de MP, como PEC, projeto de LC, resoluções, decretos legislativos etc. Contra esse entendimento, em 18.03.2009, foi impetrado o **MS 27.931**, tendo sido negada a liminar (*matéria pendente de julgamento pelo STF*, havendo forte perspectiva de ser mantida a interpretação dada pela Casa Legislativa. Em 18.03.2015, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso, já havendo 2 votos no sentido da denegação da ordem);

■ **reedição de medida provisória:** inovando, e essa talvez a grande novidade trazida pela EC n. 32/2001, o § 10 do art. 62 da CF/88 estabelece ser **vedada** a reedição de medida provisória, na mesma **sessão legislativa**, expressamente **rejeitada** pelo Congresso Nacional, ou que tenha **perdido a sua eficácia por decurso de prazo**, ou seja, não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias prorrogáveis por novos 60 dias, contados de sua publicação. Pela redação dada ao referido dispositivo legal, contudo, na sessão legislativa seguinte, permitir-se-á a reedição da aludida medida provisória, subsistindo a criticada técnica de reedição das medidas provisórias, que, infelizmente, agora conta até com permissivo constitucional expreso no sentido de corroborar a sua reedição na sessão legislativa seguinte. Restará ao Judiciário declarar inconstitucional essa nova sistemática de possibilidade de reedição da MP na sessão legislativa seguinte.

■ **9.14.4.3. Parecer prévio pela comissão mista e a inconstitucionalidade dos arts. 5.º, "caput", e 6.º, "caput", e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-**

CN

Conforme já estudamos nos *itens* 6.6.5.3 e 6.7.1.6.2, a Res. n. 1/2002-CN, integrante do *Regimento Comum*, dispôs sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, de medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do art. 62 da Constituição Federal. Os seus arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, permitiam que o parecer da comissão mista fosse emitido por relator ou relator revisor designado. Esse procedimento vinha sendo adotado na apreciação de várias medidas provisórias, até como um mecanismo de funcionalidade do procedimento. O STF, contudo, declarou-o **inconstitucional**, nulificando referidos arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN.

Isso porque o **art. 62, § 9.º, da CF/88**, que deve ser interpretado restritivamente, prescreve ser atribuição da **comissão mista** de Deputados e Senadores (e não de relator designado) **examinar** as medidas provisórias e sobre elas **emitir parecer**, de caráter **opinativo**, antes de serem **apreciadas**, em **sessão separada**, pelo **plenário** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Dessa forma, o procedimento estabelecido na Res. n. 1/2002-CN, que permite a emissão de parecer por meio de relator nomeado, e não pela comissão mista, é

inconstitucional.

Apesar de referido parecer ser **opinativo**, isso não quer dizer que possa o Parlamento violar a regra contida no art. 62, § 9.º, da CF/88. Se eventualmente não houver apreciação pela **comissão mista**, significa que a MP foi rejeitada por não apreciação, perdendo a sua eficácia desde a sua edição (art. 62, § 3.º, da CF/88).

Consoante ficou assentado na ementa do acórdão, “as comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem da **necessidade**, imposta pela Constituição, de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo Plenário seja feita de maneira inopinada, percebendo-se, assim, que o **parecer** desse colegiado representa, em

vez de formalidade desimportante, uma **garantia de que o Legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo Executivo**. O art. 6.º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela Comissão Mista, diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, é **inconstitucional**” (**ADI 4.029**, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2012, Plenário, *DJE* de 27.06.2012).

Surgia, então, a dúvida. Se o procedimento contido na Res. 1/2002-CN, que permitia a emissão de parecer por relator designado, foi declarado **inconstitucional**, que fazer em relação a todas as medidas provisórias que foram convertidas em lei sem a emissão de parecer pela comissão mista, nos termos do art. 62, § 9.º, da CF/88?

Em tese, seriam todas inconstitucionais. Para evitar essa situação de **insegurança jurídica** e diante do **excepcional interesse social**, a Corte determinou a aplicação do art. 27 da Lei n. 9.868/99 (modulação dos efeitos da decisão), declarando a inconstitucionalidade do procedimento fixado na Res. n. 1/2002-CN, **a partir da decisão proferida na ADI 4.029** — efeito *ex nunc* (j. 08.03.2012).

Dessa forma, o modelo de apreciação da medida provisória fixado na resolução do Congresso Nacional foi declarado **“ainda constitucional”** até o julgamento da referida ADI 4.029 e, a partir de então, o STF declarou inconstitucional qualquer inobservância ao art. 62, § 9.º, da CF/88, ficando, por consequência, **preservadas a validade e a eficácia** de todas as medidas provisórias convertidas em lei até aquela data, bem como daquelas que estavam tramitando no Legislativo nos termos do procedimento fixado nos arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN.

■ 9.14.4.4. Medidas a serem adotadas pelo Congresso Nacional

Tentando aclarar ainda mais a sistemática trazida pela EC n. 32/2001, podemos fixar que, adotada a MP pelo Presidente da República, o Congresso Nacional poderá tomar as seguintes medidas:

- **aprovação sem alteração;**
- **aprovação com alteração;**
- **não apreciação (rejeição tácita);**
- **rejeição expressa.**

■ **9.14.4.4.1. Aprovação sem alteração**

De acordo com o art. 12 da **Res. n. 1/2002-CN**, diferentemente do que dispunha a regra anterior, “aprovada a medida provisória, **sem alteração de mérito**, será o seu texto promulgado pelo **Presidente da Mesa do Congresso Nacional** para publicação, no Diário Oficial da União”. Cabe lembrar que, nos termos do art. 57, § 5.º, da CF/88, a Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo **Presidente do Senado Federal**. Assim, conclui-se que o Presidente do Senado Federal é quem exerce a função de Presidente da Mesa do CN.

■ **9.14.4.4.2. Aprovação com alteração**

Disciplinando a regra anterior, a Resolução n. 1/89 do Congresso Nacional, alterada pela de n. 2/89, regulamentando a matéria, previu a possibilidade de apresentação de emendas ao texto da medida provisória, originalmente expedida pelo Presidente da República.

Essa regra foi mantida na **Res. n. 1/2002-CN**. Dentro da nova sistemática, havendo emendas (**matérias correlatas ao conteúdo da medida provisória**), o *projeto de lei de conversão* apreciado por uma das casas deverá ser apreciado pela outra (tendo em vista a votação agora em **sessão separada pelo plenário de cada uma das Casas**), devendo ser, posteriormente, nos termos das regras para o processo legislativo comum, levado à apreciação do Presidente da República para sancionar ou vetar o **projeto de lei de conversão**, e, em caso de sanção ou derrubada do veto, promulgação e publicação pelo próprio Presidente da República.

No tocante à matéria alterada (diferente do texto original da medida provisória), os efeitos decorrentes desse ponto específico deverão ser regulamentados por **decreto legislativo**, perdendo a medida provisória, no ponto em que foi alterada, a eficácia desde a sua edição, como previsto no art. 62, § 3.º, da CF/88.

O art. 62, § 12, acrescentado pela **EC n. 32/2001**, estabelece que, aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta continuará integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Trata-se de verdadeira aberração jurídica, já que, se houve projeto de lei de conversão alterando o texto original da emenda, a manutenção desse texto até que o projeto seja sancionado ou vetado (pelo Chefe do Executivo) conserva em vigor dispositivo com força de lei (a medida provisória) contrário à manifestação do Parlamento, que, expressamente, o refutou. Assim, entre o período que medeia o projeto de lei de conversão e a sua sanção ou veto pelo Presidente da República, estaremos diante de ato com força normativa já execrado pelo Legislativo. Sobre a não edição do decreto legislativo *vide* item seguinte.

■ 9.14.4.4.3. Não apreciação (rejeição tácita)

A não apreciação da medida provisória no prazo de **60 dias** contados de sua publicação implicará a sua prorrogação por mais **60 dias**, como visto. Desse modo, após o período de **120 dias**, não havendo apreciação pelo Congresso Nacional, a medida provisória **perderá a eficácia desde a sua edição (rejeição tácita)**, operando efeitos retroativos, *ex tunc*, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes por **decreto legislativo** (art. 62, §§ 3.º, 4.º e 7.º).

Conforme já se observava na redação anterior, ao contrário do que acontecia com o extinto *decreto-lei*, a EC n. 32/2001 não mais permite a aprovação por **decurso de prazo**. De fato é o que se percebe pela nova redação dada ao citado art. 62, § 3.º, ou seja, a não deliberação no prazo legal acarreta a rejeição da medida provisória, que perde a eficácia desde a sua edição.

No entanto, de maneira totalmente contrária aos interesses da sociedade, resgatando as mazelas do extinto decreto-lei, o § 11 do art. 62, na nova redação, estabelece que se não for editado o **decreto legislativo** para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida provisória que perdeu a sua eficácia por ausência de apreciação, até **60 dias após a sua perda de eficácia**,¹²² “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência **conservar-se-ão por ela regidas**”; ou seja, não sendo editado o decreto legislativo pelo Congresso Nacional, valerão as regras da medida provisória para regulamentar as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante o período em que a MP produzia efeitos. Ora, se a perda dos efeitos é *ex tunc*, como afirmar que as relações jurídicas **conservar-se-ão regidas** pela extinta MP? *Data maxima venia*, trata-se de verdadeiro resgate do autoritário **decreto-lei**, que permitia a sua aprovação por decurso de prazo. Aqui se diz que a não apreciação (decurso de prazo) implica a perda da eficácia *ex tunc*. Mas, inexistindo o decreto legislativo, as relações serão regidas pela extinta medida provisória! Com o devido respeito, muito embora tenhamos a missão de dizer o que o examinador dos concursos possa perguntar em uma primeira fase, não deixamos de declarar a nossa repulsa por essa nova sistemática, totalmente inconstitucional e arbitrária. De acordo com a justificação do **Projeto de Resolução n. 5 — CN** (DCN, 03.10.2001, p. 19989), por outro lado, o objeto dessa regra é “evitar vácuo jurídico (...) evidenciado na prática recente”.

Apenas para sistematizar algo que já foi dito, indaga-se: é permitida a reedição de medida provisória que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo, ou seja, não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias prorrogáveis por outros 60 dias?

O art. 62, § 10, da CF/88 estabelece ser **vedada** a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha **perdido sua eficácia por decurso de prazo**. Então, pela nova regra, a reedição da aludida MP não será permitida na mesma sessão legislativa, isto é, de acordo com o art. 57, *caput*, na redação dada pela EC n. 50/2006, no período durante o qual o Congresso Nacional, anualmente, reúne-se em Brasília e que vai de **2 de**

fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro. Na sessão legislativa seguinte, abre-se a possibilidade de reedição da MP.

■ 9.14.4.4.4. *Rejeição expressa*

O Congresso Nacional também poderá **expressamente** deixar de converter a medida provisória em lei, devendo disciplinar os efeitos dela decorrentes por meio de **decreto legislativo**.

Reforçando a crítica por nós já manifestada, o novo art. 62, § 11, diz que se não for editado o decreto legislativo até **60 dias** da rejeição da medida provisória, a qual, como referido, perde a eficácia desde a sua edição, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela (pela medida provisória **rejeitada**) regidas.

Retomando os argumentos expendidos no item anterior, trata-se de regra até mais abrangente que o execrado e ditatorial decreto-lei da Constituição anterior, que permitia a aprovação por decurso de prazo. Se o Congresso Nacional **rejeitou** a MP, expressamente, como admitir que, inexistindo o decreto legislativo, as regras fixadas pela MP continuem a disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes? Não se pode aceitar essa situação.

Outra pergunta que se faz: a reedição de MP expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional é permitida?

Como visto no item anterior, o art. 62, § 10, estabelece ser **vedada a reedição, na mesma sessão legislativa**, de medida provisória que tenha sido **rejeitada** ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

Logo, *a contrario sensu*, pela literalidade da EC n. 32/2001, na sessão legislativa seguinte seria permitida a reedição da MP, mesmo se expressamente rejeitada. Essa atrocidade acobertada por todos não pode iludir a população. Todos vêm dizendo ser “vedada a reedição de MP” — o grande avanço trazido pela novel emenda constitucional! No entanto, a literalidade do aludido parágrafo esconde artifícios para que o governo reedite medidas provisórias, inclusive se expressamente rejeitadas. Restará ao STF declarar inconstitucional esse

“*Frankenstein* jurídico”, já que, na sistemática anterior, o Pretório Excelso vedava a reedição de MP quando houvesse expressa rejeição pelo Congresso Nacional (cf. ADI 1.250-9/DF, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* 1, de 06.09.1995, p. 28252; ADI 293-7/600/DF, Pleno, medida liminar, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ADI 295-3, Rel. Min. Carlos Velloso).

■ 9.14.4.5. *Impacto da medida provisória sobre o ordenamento jurídico*

Publicada a medida provisória e tendo ela força de lei, as demais normas do ordenamento, que com ela sejam incompatíveis, terão a sua **eficácia suspensa**. Rejeitada a medida provisória, a lei que teve a sua eficácia suspensa volta a produzir efeitos (**lembrando que não foi revogada pela medida provisória**). Aprovada e convertida em lei, a **nova lei** (fruto da conversão) revogará a lei anterior, se com ela incompatível, ou se tratar inteiramente de matéria de que tratava a lei anterior. [123](#)

Novamente, em razão do objetivo deste trabalho, que é ajudar os ilustres candidatos a vencer as dificuldades dos concursos públicos, lembramos a criticada redação dada ao art. 62, § 11, da CF/88, que traz uma exceção aos casos que tenham sido atingidos pela medida provisória. Embora a rejeição da MP, como visto, implique o restabelecimento da norma anterior, tendo em conta a sua desconstituição com efeitos retroativos, desde que não tenha sido “... editado o **decreto legislativo** a que se refere o § 3.º até **60 dias** após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”. Mais uma vez expressamos o nosso repúdio a essa regra, alertando os candidatos a concursos públicos da sua existência!

■ 9.14.4.6. *Pode o Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória já editada?*

A partir do momento que o Presidente da República edita a MP, ele não mais

tem controle sobre ela, já que, **de imediato**, deverá submetê-la à análise do Congresso Nacional, não podendo retirá-la de sua apreciação.

Por outro lado, conquanto contrariando a nossa posição, devemos alertar para a “... orientação assentada no STF no sentido de que, não sendo dado ao Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória que tiver editado, é-lhe, no entanto, possível ab-rogá-la por meio de nova medida provisória, valendo tal ato pela simples suspensão dos efeitos da primeira, efeitos esses que, todavia, o Congresso poderá ver restabelecidos, mediante a rejeição da medida ab-rogatória...” (ADI 1.315-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, *DJ* de 25.08.1995, p. 26022, *Ement.* v. 01797-02, p. 293, Pleno).

■ **9.14.4.7. Limitação material à edição de medidas provisórias, de acordo com a EC n. 32/2001**

A **EC n. 32/2001** trouxe algumas novidades em relação aos limites materiais de edição das medidas provisórias, notadamente na redação dada aos §§ 1.º e 2.º do art. 62.

Assim, é expressamente **vedada** a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas:

- à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- a direito penal, processual penal e processual civil;
- à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, à carreira e à garantia de seus membros;
- a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3.º. [124](#)

A) MP pode ser editada para a abertura de crédito extraordinário?

A regra é que a MP não pode tratar de matéria orçamentária. Contudo, como se verifica na parte final do art. 62, § 1.º, I, “d”, ressalva-se a utilização de MP para a **abertura de crédito extraordinário**, mas desde que se observe o art.

167, § 3.º.

Trata-se daquilo que vem sendo chamado pela jurisprudência do STF de **limites constitucionais à atividade legislativa excepcional do Poder Executivo na edição de MP para a abertura de crédito extraordinário**.

Portanto, de acordo com o art. 167, § 3.º, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas **imprevisíveis** e **urgentes**, como as decorrentes de **guerra**, **comoção interna** ou **calamidade pública**, observado o disposto no art. 62.

Assim, a utilização da MP fica restrita a essas situações extraordinárias, destacando-se o importante papel de controle da atividade do Executivo pelo Judiciário. É o que estudamos no próximo item.

B) É possível o controle jurisdicional de medida provisória que abre crédito extraordinário?

Conforme já estudado, [125](#) revisando o conceito de lei de efeito concreto (ADI 4.048 e 4.049), o STF tem admitido o controle dos requisitos de **imprevisibilidade** e **urgência** para a edição de MP que abre crédito extraordinário.

Isso porque o art. 167, § 3.º, ao dispor que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas **imprevisíveis** e **urgentes**, como as decorrentes de **guerra**, **comoção interna** ou **calamidade pública**, não obstante estabeleça um rol exemplificativo do que venha a ser “despesas imprevisíveis e urgentes”, há uma indiscutível **densificação normativa** dos referidos requisitos, podendo, então, o STF realizar o controle:

“Ementa: Ao contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os requisitos de imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 3.º) recebem densificação normativa da Constituição. Os conteúdos semânticos das expressões ‘guerra’, ‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ constituem vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3.º, c/c o art. 62, § 1.º, inciso I, alínea d, da Constituição...” (ADI 4.048-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.05.2008,

DJE de 22.08.2008. No mesmo sentido: ADI 4.049-MC, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05.11.2008, *Inf. 527/STF*) (**matéria pendente de julgamento no STF**).[126](#)

C) Outras vedações

A regra trazida na EC n. 32/2001 **veda** ainda, expressamente, a edição de medida provisória:

- que vise à detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;[127](#)
- reservada à lei complementar (lembrem que o aspecto material da lei complementar foi taxativo e expressamente previsto na Constituição Federal e, no tocante ao aspecto formal, o *quorum* de maioria absoluta);
- já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

No tocante à **matéria tributária**, a EC n. 32/2001 estabelece a seguinte regra (art. 62, § 2.º):

- medida provisória que implique **instituição** ou **majoração** de **impostos**, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

Essa nova redação, apesar de contrariar renomada parte da doutrina,[128](#) não altera o posicionamento do STF, que entende ser perfeitamente possível a regulamentação de matéria tributária através de medida provisória, exceto nas hipóteses em que a Constituição exige lei complementar, por exemplo, o art. 146, devendo, contudo, ser observado o princípio da **anterioridade tributária**[129](#) (art. 150, III, “b”) e, nas hipóteses cabíveis, o **princípio da carência**, fixado no art. 150, III, “c” (EC n. 42/2003).

Em relação a este princípio, todavia, a EC n. 32/2001 trouxe uma novidade. O STF posicionava-se no sentido de tomar por base a data da primeira edição da medida provisória, a fim de ver preenchido o requisito do art. 150, III, “b”, ou do art. 195, § 6.º (cf. ADI 1.617-MS, Rel. Min. Octavio Gallotti, *DJ* de

15.08.1997; ADI 1.610-DF, Rel. Min. Sydney Sanches; RE 221.856-PE, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.^a Turma, 25.05.1998, e o entendimento pacificado na **S. 651/STF, 24.09.2003**).

Com a redação dada ao art. 62, § 2.º, excepcionando a regra geral exposta pelos julgados do STF, em se tratando da espécie tributária denominada **imposto**, com exceção daqueles que dispensam respeito ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, § 1.º, c/c os arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II), a sua instituição ou majoração, por **medida provisória**, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte (art. 150, III, “b”) se a aludida MP tiver sido convertida em lei até o último dia do exercício financeiro em que foi editada.

Outro limite previsto pela EC n. 32/2001 vem disciplinado na redação dada ao **art. 246 da CF/88**, agora redigido nos seguintes termos:

“Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na **regulamentação** de artigo da Constituição cuja **redação** tenha sido **alterada** por **meio de emenda** promulgada entre 1.º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive”.

Trata-se de mais um **retrocesso** trazido pela nova sistemática das medidas provisórias, beneficiando, claramente, o governo e mostrando que o Congresso Nacional cedeu e muito nesse mau acordo político.

Isso porque a vedação de regulamentação de artigo da Constituição alterado por emenda, de acordo com a redação dada ao art. 246 da CF/88, não abrange as que forem promulgadas após o dia **11.09.2001**. Pela nova regra, retrógrada, enfatize-se, as MPs não poderão regulamentar artigos da Constituição que tenham sido alterados por emenda constitucional no período de **1.º.01.1995** a **11.09.2001**. Todo artigo da Constituição que for alterado antes ou depois desse período poderá ser regulamentado por MP. Naturalmente, interpretando a literalidade do dispositivo, mesmo durante referido período, antes ou depois, os artigos da Constituição que não forem alterados por emenda (e, claro, desde que não haja qualquer vedação constitucional — limites materiais) poderão ser regulamentados por MP.

Além desses limites, podemos destacar, muito embora não estejam previstos

expressamente na **EC n. 32/2001**, os seguintes, impossibilitando a regulamentação por medida provisória das:

■ **matérias que não podem ser objeto de delegação legislativa** (art. 68, § 1.º, pela própria natureza do ato que reforça o princípio da indelegabilidade de atribuições);

■ **matérias reservadas às resoluções e aos decretos legislativos**, por serem de competência das Casas ou do próprio Congresso Nacional.

Por fim, em relação aos limites materiais, selecionamos, ainda, algumas situações nas quais já havia expressa vedação de regulamentação por medida provisória:

■ **art. 25, § 2.º, da CF/88**: “cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação”;

■ **art. 73 do ADCT**: acrescentado pela ECR n. 1/94, que já teve a sua **eficácia exaurida**, vedando a regulação do Fundo Social de Emergência, criado inicialmente para os exercícios financeiros de 1994 e 1995, por medida provisória;

■ **art. 2.º da EC n. 8/95**: veda a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21 da CF/88; [130](#)

■ **art. 3.º da EC n. 9/95**: veda a adoção de medida provisória na regulamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e nos §§ 1.º e 2.º do art. 177 da CF/88.

■ **9.14.4.8. O que acontecerá com as medidas provisórias editadas em data anterior à EC n. 32/2001?**

O art. 2.º da **EC n. 32/2001** estabeleceu que “as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.

Isso significa que todas as medidas provisórias anteriores à publicação da EC

n. 32/2001, caso não sejam derrubadas pelo Congresso, ou o Executivo deixe de revogá-las “explicitamente”, diz o texto (entendemos, também, a revogação tácita como aplicável ao caso), continuarão em vigor, implicando a **indesejável perpetuação**. Resta ao Judiciário apreciar a nova sistemática, afastando-a, pois, assim permanecendo, ter-se-á, mais uma vez e disfarçadamente, uma aprovação por decurso de prazo. Conforme já declarado por alguns parlamentares, é humanamente impossível apreciar todas as medidas provisórias, o que implica, pela regra definida, a sua **vigência indeterminada**. [131](#)

Não podemos deixar de consignar o nosso repúdio a essa nova regra, que, de certa forma, implica a perpetuação das medidas provisórias em vigor antes da publicação da aludida emenda constitucional.

Como o texto diz **publicação**, não podemos confundir o termo final com a **promulgação**. Como se sabe, a EC n. 32/2001 foi **promulgada** em **11.09.2001**, e **publicada** em **12.09.2001** (*DOU* de 12.09.2001, p. 1, col. 1), este último, portanto, o termo final para a verificação das medidas provisórias em vigor.

Por fim, cumpre lembrar que, embora as regras sobre a apreciação pelo Congresso Nacional das MPs estejam contidas na **Res. n. 1/2002-CN**, de acordo com o seu art. 20, às medidas provisórias em vigor na data da publicação da EC n. 32/2001 aplicar-se-ão os procedimentos previstos na **Res. n. 1/89-CN**, alterada pela **Res. n. 2/89-CN**.

■ 9.14.4.9. *Um alerta*

Até o fechamento desta edição, a **PEC n. 72/2005-SF** já havia sido aprovada em 2 turnos no Senado Federal e remetida à Câmara dos Deputados (**PEC 511/2006-CD**).

Se aprovada, dentre outras novidades, **mudará as regras** para edição e tramitação das medidas provisórias, que não mais teriam força de lei assim que editadas pelo Executivo. As MPs gerariam efeitos legais apenas depois de ter os critérios de urgência e relevância avaliados, em até 3 dias úteis, pelas Comissões

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJs) da Câmara ou Senado — onde primeiro a MP ingressar —, já que, pela PEC, as medidas provisórias passam também a iniciar sua tramitação alternadamente nas duas Casas legislativas.

■ 9.14.5. Decreto legislativo

■ 9.14.5.1. Aspectos gerais

O decreto legislativo, uma das espécies normativas previstas no art. 59 (inciso VI), é o instrumento normativo por meio do qual serão materializadas as **competências exclusivas do Congresso Nacional**, alinhadas nos incisos I a XVII do art. 49 da CF/88.¹³² As regras sobre o seu procedimento vêm contempladas nos Regimentos Internos das Casas ou do Congresso.

Além das matérias do art. 49 da CF/88, o Congresso Nacional deverá regulamentar, por decreto legislativo, os efeitos decorrentes da medida provisória não convertida em lei. Essa regra vem agora expressamente prevista no art. 62, § 3.º, da CF/88, introduzido pela **EC n. 32/2001**.

Deflagrado o processo legislativo, ocorrerá a discussão no Congresso, e, havendo aprovação do projeto (pela maioria simples — art. 47), passa-se, imediatamente, à promulgação, realizada pelo **Presidente do Senado Federal**, que determinará a sua publicação. **Não** existe manifestação do Presidente da República, sancionando ou vetando, pela própria natureza do ato (pois versa sobre matérias de competência do Congresso, conferindo subjetividade ao regulamentar o art. 49), bem como em virtude de expressa previsão constitucional (art. 48, *caput*).

■ 9.14.5.2. Breves notas sobre o processo de formação dos tratados internacionais e a novidade trazida pela EC n. 45/2004

■ 9.14.5.2.1. Tratados e convenções internacionais gerais

Dentre as várias hipóteses previstas no art. 49 da CF/88, destaca-se a **competência exclusiva** do Congresso Nacional, materializada, como visto, por meio de **decreto legislativo**, para “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” (art. 49, I — *com alta incidência de questionamento nos concursos públicos*).

Deixamos bem claro que a análise do referido instituto tem por objetivo único esclarecer como se aperfeiçoa a formação dos tratados internacionais e como estes passam a integrar o ordenamento jurídico brasileiro. Não se tem a intenção de trazer em pauta as várias teorias e discussões travadas entre os internacionalistas, mesmo porque fugiria por completo do objetivo da presente proposta.

Basicamente são duas as possíveis formas por meio das quais se origina um tratado internacional: *a)* pela aprovação do texto por uma instância de organização internacional, ou *b)* pela assinatura de um documento por sujeitos de direito internacional público. Normalmente, tem-se: **negociação**, **conclusões** e **assinatura** do tratado. Nos dizeres de Flávia Piovesan, “a assinatura do tratado, via de regra, indica tão somente que o tratado é autêntico e definitivo”. E prossegue a autora lembrando a Convenção de Viena, fixando, em linhas gerais, que “o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado pode ser expresso mediante a assinatura, troca de instrumentos constituintes do tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou através de qualquer outro meio acordado (arts. 11 a 17 da Convenção)”. [133](#)

Em relação ao Brasil, como deflui da análise do **art. 84, VIII**, da CF/88, é de **competência privativa** do **Presidente da República** “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”. Essa regra deve ser associada, como vimos acima, ao **art. 49, I**, da CF/88, que estabelece como de **competência exclusiva** do Congresso Nacional, materializada através da elaboração de **decreto legislativo** (art. 59, VI, da CF/88), resolver, definitivamente, sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Assim, primeiro há a **celebração do tratado, convenção ou ato internacional** pelo Presidente da República (art. 84, VIII), para, depois e internamente, o Parlamento decidir sobre a sua viabilidade, conveniência e oportunidade.¹³⁴ Desta feita, concordando o Congresso Nacional com a celebração do ato internacional, elabora-se o **decreto legislativo**, que é o instrumento adequado para **referendar** e **aprovar** a decisão do Chefe do Executivo, dando-se a este “carta branca” para **ratificar** a assinatura já depositada, ou, ainda, **aderir**, se já não o tiver feito. **Ratificar** significa **confirmar** perante a ordem internacional que aquele Estado, definitivamente, obriga-se perante o pacto firmado. Tecnicamente, a **ratificação** não é ato do Parlamento, mas de competência privativa do Chefe do Executivo, típico ato de direito internacional público. A **troca** (geralmente nos acordos bilaterais) ou o **depósito** (em regra, nos multilaterais, no órgão responsável pela custódia, como, *verbi gratia*, a ONU, a OEA...) do aludido instrumento de ratificação asseguram a obrigatoriedade do Estado no âmbito internacional.¹³⁵

A próxima etapa, portanto, com o objetivo de que o tratado se **incorpore** por definitivo ao **ordenamento jurídico interno**, é a fase em que o Presidente da República, mediante **decreto**, **promulga** o texto, **publicando-o**, em **português**, em órgão da imprensa oficial, dando-se, pois, ciência e publicidade da ratificação da assinatura já lançada, ou, caso esta não se tenha externado, da adesão a determinado tratado ou convenção de direito internacional. Como maestralmente assinala Mirtô Fraga, “o decreto do Presidente da República atestando a existência da nova regra e o cumprimento das formalidades requeridas para que ela se concluísse, com a ordem de ser cumprida tão inteiramente como nela se contém, confere-lhe (ao tratado) força executória, e a publicação exige sua observância por todos: Governo, particulares, Judiciário”.¹³⁶

De acordo com o posicionamento do STF, a expedição, pelo Presidente da República, do referido **decreto**, acarreta três efeitos básicos que lhe são inerentes: a) a **promulgação** do tratado internacional; b) a **publicação** oficial de seu texto; e c) a **executoriedade** do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno.

Referido ato normativo integra o ordenamento jurídico interno com caráter de **norma infraconstitucional**, situando-se nos mesmos planos de validade, eficácia e autoridade em que se posicionam as leis ordinárias (guardando, dessa forma, estrita relação de **paridade normativa** com as referidas **leis ordinárias**),¹³⁷ podendo, por conseguinte, ser revogado (*ab-rogação* ou *derrogação*) por norma posterior, bem como ser questionada a sua constitucionalidade perante os tribunais, de forma concentrada ou difusa.¹³⁸

Constata-se, pois, que o sistema constitucional brasileiro **não** exige, para efeito de executóriedade doméstica dos tratados internacionais, a edição de lei formal distinta (visão **dualista extremada** ou **radical**), satisfazendo-se com a adoção de *iter procedimental* complexo, que compreende a **aprovação congressional** e a **promulgação executiva do texto convencional**. Isso quer dizer que o Brasil adotou o princípio do **dualismo moderado**.

Podemos, então, resumir o trâmite de integração da norma internacional no direito interno a quatro fases distintas, a saber:

- **celebração do tratado internacional** (negociação, conclusão e assinatura) pelo **Órgão do Poder Executivo** (ou posterior adesão [terceira etapa], art. 84, VIII — Presidente da República);
- **aprovação** (**referendo** ou “**ratificação**” *lato sensu*), pelo Parlamento, do tratado, acordo ou ato internacional, por intermédio de **decreto legislativo**, resolvendo-o definitivamente (Congresso Nacional — art. 49, I);
- **troca** ou **depósito** dos instrumentos de **ratificação** (ou **adesão**, caso não tenha tido prévia celebração) pelo **Órgão do Poder Executivo** em âmbito internacional;
- **promulgação** por **decreto presidencial**, seguida da **publicação** do texto em português no *diário oficial*. Neste momento o **tratado, acordo ou ato internacional adquire executóriedade no plano do direito positivo interno**, guardando estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias** (salvo nas hipóteses em que o tratado ou convenção internacional versar sobre direitos humanos e tiver sido incorporado(a) com a natureza supralegal ou constitucional (cf. art. 5.º, § 3.º, e discussão no

item 9.14.5.2.3).

Na observação precisa de Louis Henkin, “... o poder de celebrar tratados — como é concebido e como de fato se opera — é uma autêntica expressão do constitucionalismo; claramente ele estabelece a sistemática de ‘*checks and balances*’. Ao atribuir o poder de celebrar tratados ao Presidente, mas apenas mediante o referendo do legislativo, busca-se limitar e descentralizar o poder de celebrar tratados, prevenindo o abuso desse poder. Para os constituintes, o motivo principal da instituição de uma particular forma de ‘*checks and balances*’ talvez fosse o de proteger o interesse de alguns Estados, mas o resultado foi o de evitar a concentração do poder de celebrar tratados no Executivo, como era então a experiência europeia”. [139](#)

■ **9.14.5.2.2. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (EC n. 45/2004)**

Conforme mencionado no *item 6.7.1.2.7* (estudo sobre o objeto da ADI), retomamos a importante discussão sobre a inserção, pela **EC n. 45/2004**, do § 3.º ao art. 5.º da CF/88, nos seguintes termos: “os tratados e convenções internacionais [140](#) sobre **direitos humanos** que *forem* aprovados, **em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, por **três quintos dos votos dos respectivos membros**, serão equivalentes às **emendas constitucionais**”.

Zulaiê Cobra, em seu parecer sobre a Reforma, pondera que, “buscando efetividade da prestação jurisdicional, acolhemos também sugestão do Ministro Celso de Mello... no sentido da outorga explícita de hierarquia constitucional aos tratados celebrados pelo Brasil, em matéria de direitos humanos, à semelhança do que estabelece a Constituição argentina... com a reforma de 1994 (art. 75, n. 22), introdução esta no texto constitucional que afastará a discussão em torno do alcance do art. 5.º, § 2.º”. [141](#)

Entendemos que a nova regra não é inconstitucional e não fere nem mesmo os limites implícitos do poder de reforma, destacando-se, nesse sentido, o **Decreto n. 6.949, de 25.08.2009**, que promulga a *Convenção sobre os Direitos*

das Pessoas com Deficiência, e de seu *Protocolo Facultativo*, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, que já havia sido aprovada pelo **Decreto Legislativo n. 186/2008**, tendo sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de **norma constitucional**.

Esquematizando, podemos afirmar, então, conforme já exposto, que:

■ **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e desde que aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional e em 2 turnos de votação (cf. art. 60, § 2.º, e art. 5.º, § 3.º):** equivalem a **emendas constitucionais**, guardando, desde que observem os “limites do poder de reforma”, estrita relação de paridade com as *normas constitucionais*;

■ **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pela regra anterior à Reforma e desde que não confirmados pelo quorum qualificado:** malgrado posicionamento pessoal deste autor, já exposto, para as provas, seguindo o entendimento do STF, terão natureza **supralegal** (cf. *item 9.14.5.2.3*); [142](#)

■ **tratados e convenções internacionais de outra natureza:** têm força de lei ordinária.

Dessa maneira, deverão surgir duas espécies do gênero *tratados e convenções internacionais*: **a)** aqueles sobre direitos humanos e **b)** aqueles outros que não disponham sobre direitos humanos. Os primeiros se dividem em: **a.1)** tratados sobre *direitos humanos* aprovados pelo *quorum* e observância de turnos das emendas constitucionais, tendo a equivalência destas; e **a.2)** os que não seguiram essa formalidade, sendo, segundo o STF, *supralegais*.

Flávia Piovesan identificou uma clara relação entre a **redemocratização do Estado brasileiro**, a partir de 1985, e o **processo de incorporação de relevantes instrumentos de proteção aos direitos humanos**.

Em valiosa compilação, a ilustre colega observa que “... a partir da Carta de 1988 foram ratificados pelo Brasil: *a)* a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; *b)* a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de

1989; c) a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; d) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; e) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; g) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995; h) o Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de Morte, em 13 de agosto de 1996; i) o Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996; j) o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho de 2002; k) o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 28 de junho de 2002; e l) os dois Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança, referentes ao envolvimento de crianças em conflitos armados e à venda de crianças e prostituição e pornografia infantis, em 24 de janeiro de 2004. A estes avanços, soma-se o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em dezembro de 1998”. [143](#)

Qual a natureza jurídica desses tratados e convenções que tratam de direitos humanos anteriores à EC n. 45/2004?

Diferentemente da regra da Constituição da Argentina, que é expressa em afirmar que os tratados anteriores sobre direitos humanos passam a ter, com a Reforma de 1994, hierarquia constitucional, a regra brasileira foi omissa.

Entendemos que o Congresso Nacional poderá (e, querendo atribuir natureza constitucional, deverá) **confirmar** os tratados sobre direitos humanos pelo *quorum* qualificado das emendas e, somente se observada essa formalidade, e desde que respeitados os *limites do poder de reforma das emendas*, é que se poderá falar em tratado internacional de “natureza constitucional”, ampliando os direitos e garantias individuais do art. 5.º da Constituição.

E qual a diferença entre os *tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos* aprovados (ou confirmados) em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros e aqueles, também

sobre direitos humanos, que não seguiram a aludida formalidade?

A diferença estará no procedimento da **denúncia** (ato de retirada do tratado). Enquanto aqueles que seguiram um procedimento mais solene dependem de **prévia autorização** do Congresso Nacional, também em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, em cada uma de suas Casas, os outros (nos mesmos termos daqueles que não dispõem sobre direitos humanos) poderão ser denunciados normalmente pelo Executivo, sem a prévia autorização do Congresso Nacional.

Nesse sentido, também, Piovesan, que os classifica (os tratados sobre **direitos humanos**) em: **a) material e formalmente constitucionais** (aqueles que equivalem às emendas constitucionais em razão do procedimento de incorporação mais solene) e **b) materialmente constitucionais**, que, apesar de tratarem de **direitos humanos**, não passaram pelo procedimento mais solene. [144](#)

Para a ilustre Procuradora do Estado de São Paulo, os *tratados material e formalmente constitucionais* **não podem ser objeto de denúncia unilateral pelo Executivo**, já que “... os direitos neles enunciados receberam assento no texto constitucional não apenas pela matéria que veiculam, mas pelo grau de legitimidade popular contemplado pelo especial e dificultoso processo de sua aprovação, concernente à maioria de três quintos dos votos dos membros, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação. Ora, se tais direitos internacionais passaram a compor o quadro constitucional, não só no campo material, mas também formal, não há como admitir que um ato isolado e solitário do Poder Executivo subtraia tais direitos do patrimônio popular — ainda que a possibilidade de denúncia esteja prevista nos próprios tratados de direitos humanos ratificados... É como se o Estado houvesse renunciado a esta prerrogativa de denúncia, em virtude da ‘constitucionalização formal’ do tratado no âmbito jurídico interno”. [145](#)

E qual seria o procedimento para a aprovação pelo quorum qualificado das emendas?

A nosso ver, pela regra do art. 49, I (que não poderá ser desprezada),

continua sendo o **decreto legislativo** o ato pelo qual o Congresso Nacional, no procedimento de incorporação dos tratados internacionais, resolve definitivamente sobre os tratados e convenções internacionais referentes a direitos humanos. Veja que a nova regra não diz que o procedimento deverá ser o das emendas, mas que, cumpridas as formalidades, **equivalerão** às emendas.

A única diferença está na possibilidade (e veja que há uma permissão, e não um dever para o Congresso Nacional) de se atribuir caráter de emenda constitucional aos tratados e convenções sobre direitos humanos, mas somente se observadas as formalidades fixadas no art. 5.º, § 3.º.

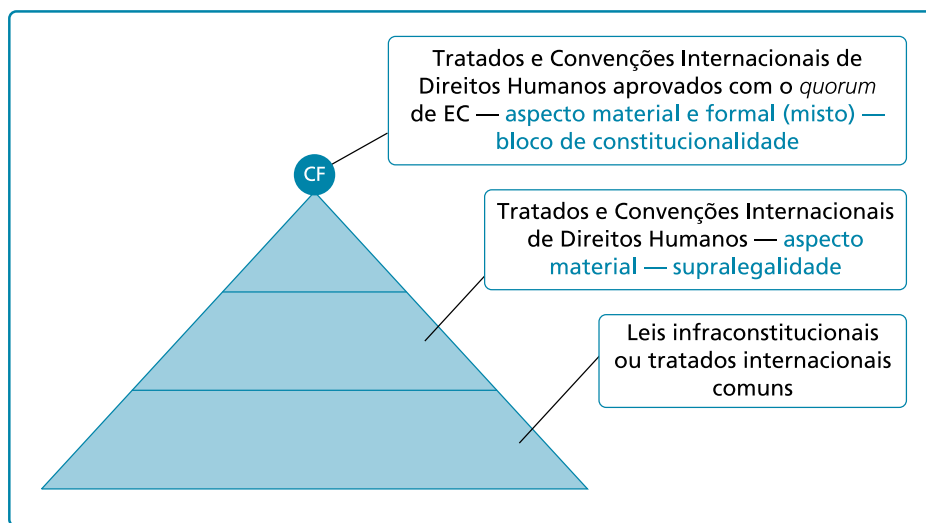
Perceba que o texto diz: “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que **forem** aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”, significando que poderemos deparar com aprovação sem as aludidas formalidades e, aí, segundo o STF, referidos tratados terão natureza *supralegal*.

Por fim, conforme já analisado no *item 6.7.1.3*, ampliando o conceito de “bloco de constitucionalidade”, passamos a ter, com a Reforma, um outro *parâmetro constitucional de confronto*, quais sejam, os tratados e convenções internacionais com “força” de norma constitucional. Assim, perfeitamente possível que uma lei seja declarada **inconstitucional** por ferir referido tratado internacional sobre direitos humanos, que tenha sido aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, já que equivalerão às emendas constitucionais.

Para todos os casos, entendemos ainda prevalecer a afirmação exarada por Araujo e Nunes Júnior em relação à regra anterior: “o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto legislativo que ratifica um tratado internacional não torna o ajuste internacional nulo, mas apenas exclui o Brasil de seu cumprimento, sujeitando-o, no entanto, a sanções internacionais decorrentes do descumprimento”. [146](#)

■ 9.14.5.2.3. A “supralegalidade” dos tratados e convenções

internacionais sobre direitos humanos



O STF decidiu a matéria em dois recursos extraordinários (**RE 466.343 e RE 349.703**) buscando enfrentar a constitucionalidade da prisão civil para o inadimplente em contratos de alienação fiduciária em garantia. [147](#)

De acordo com o voto [148](#) do Ministro Gilmar Mendes, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderiam, seguindo a doutrina, ter o seguinte *status normativo*:

- **natureza supraconstitucional** (*Celso Duvivier de Albuquerque Mello*);
- **caráter constitucional** (*Antônio Augusto Cançado Trindade e Flávia Piovesan*);
- **status de lei ordinária** (*RE 80.004/SE, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ de 29.12.1977*);
- **caráter supralegal** (*art. 25 da Constituição da Alemanha; art. 55 da Constituição da França; art. 28 da Constituição da Grécia e a posição firmada pelo Ministro Gilmar Mendes em referido voto*).

Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes, acompanhando o voto do relator, acrescentou os seguintes fundamentos: “(...) parece mais consistente a interpretação que atribui a característica de **supralegalidade** aos tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os

tratados sobre direitos humanos seriam **infraconstitucionais**, porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de **supralegalidade**. Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana” (grifamos).

Prosseguindo, sustentou que a previsão, pelo Pacto e pela Convenção internacionais, da prisão por dívida exclusivamente para o devedor de alimentos “tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, **a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel** (art. 5.º, inciso LXVII) **não foi revogada** pela ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos — Pacto de San José da Costa Rica (art. 7.º, 7), **mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria**, incluídos o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e o Decreto-lei n. 911, de 1.º de outubro de 1969”.

Concluindo, afirmou que a prisão civil do devedor-fiduciante afronta o **princípio da proporcionalidade**, na medida em que existem outros meios “processuais-executórios postos à disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, bem como em razão de o DL 911/69, na linha do que já considerado pelo relator, ter instituído uma ficção jurídica ao equiparar o devedor-fiduciante ao depositário, em ofensa ao princípio da reserva legal proporcional” (*Inf. 449/STF*).

O STF, por 5 x 4, em **03.12.2008**, no julgamento do **RE 466.343**, decidiu que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se não incorporados na forma do art. 5.º, § 3.º (quando teriam natureza de norma constitucional), têm natureza de normas **supralegais**, paralisando, assim, a eficácia de todo o ordenamento infraconstitucional em sentido contrário. [149](#)

Embora sedutora a tese e, sem dúvida, fortalecedora do princípio da **dignidade da pessoa humana**, o grande problema parece-nos justificar (especialmente diante da redação conferida ao § 3.º do art. 5.º pela EC n. 45/2004) a possibilidade de “paralisar” a eficácia das leis contrárias aos tratados ou convenções sobre direitos humanos, mas que encontrariam suporte de validade na própria Constituição, que continua estabelecendo, ao lado da prisão do devedor de alimentos, a do depositário infiel (remetemos o amigo leitor para o *item 6.7.1.2.7*).

Finalmente, destaca-se a **SV 25/2009**: “é **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

■ 9.14.6. Resolução

Por meio das resoluções regulamentar-se-ão as matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados (art. 51), do Senado Federal (art. 52) e algumas de competência do Congresso Nacional, fixadas, além das poucas hipóteses constitucionais, regimentalmente.

Assim, os Regimentos Internos determinam as regras sobre o processo legislativo. De modo geral, deflagrado o processo legislativo na forma do Regimento, a discussão dar-se-á nas respectivas Casas, ou seja, em se tratando de projeto de resolução da Câmara dos Deputados, apenas nessa Casa; quando for projeto do Senado Federal, **unicameralmente**, na referida Casa e, na hipótese de resolução do Congresso Nacional, a tramitação será **bicameral**.

Uma vez aprovado (**maioria simples** — art. 47), passa-se à promulgação, que será realizada pelo Presidente da Casa (Câmara ou Senado) e, no caso de resolução do Congresso, pelo Presidente do Senado Federal. Os mencionados Presidentes determinarão a publicação.

Além da previsão regimental de matérias a serem regulamentadas por **resoluções**, assim como aquelas dos arts. 51 e 52 da CF/88, destacamos outras hipóteses constitucionais:

■ **art. 68, § 2.º**: o Congresso Nacional delegará competência ao

Presidente da República para elaborar a **lei delegada** por meio de **resolução**;

■ **art. 155, § 1.º, IV**: o Senado Federal, por meio de **resolução**, fixará as **alíquotas máximas** do imposto sobre transmissão *causa mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos, a ser instituído pelos Estados e pelo DF;

■ **art. 155, § 2.º, IV**: o Senado Federal, por meio de **resolução** de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

■ **art. 155, § 2.º, V, “a”**: faculta-se ao Senado Federal estabelecer **alíquotas mínimas** nas operações internas, mediante **resolução** de **iniciativa** de 1/3 e aprovada pela **maioria absoluta** de seus membros em relação ao imposto a ser instituído pelos Estados e pelo DF sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (**ICMS**), ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

■ **art. 155, § 2.º, V, “b”**: faculta-se, também, ao Senado Federal fixar **alíquotas máximas** nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante **resolução** de iniciativa da **maioria absoluta** e aprovada por **2/3** de seus membros.

Também, e pelos mesmos motivos apontados quando definimos o decreto legislativo, **não** haverá manifestação presidencial sancionando ou vetando o projeto de resolução (art. 48).

CUIDADO: devemos lembrar, em relação às hipóteses dos **arts. 51, IV**, e **52, XIII**, que cada Casa não pode mais, de acordo com a regra fixada pela EC n. 19/98, dispor mediante resolução sobre a **remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços**, tendo, apenas, **a iniciativa reservada** para o encaminhamento de **projeto de lei**, que, no caso, deverá ser sancionado pelo Presidente da República.

Já que falamos em decreto legislativo, resta observar que, enquanto as resoluções podem instrumentalizar matérias de competência da CD, do SF ou do CN, os decretos legislativos só servirão para regulamentar as matérias de

competência exclusiva do CN, indicadas no art. 49 da CF/88.

■ 9.14.7. Quadro comparativo das espécies normativas

ESPÉCIES NORMATIVAS	LOCALIZAÇÃO E ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Emendas à Constituição	■ Art. 60: <i>quorum</i> : 3/5, em cada Casa, em dois turnos de votação
Lei Complementar	■ Art. 69: <i>quorum</i> : maioria absoluta. Hipóteses taxativamente previstas nos arts. 7.º, I; 14, § 9.º; 18, §§ 2.º, 3.º e 4.º; 21, IV; 22, parágrafo único; 23, parágrafo único; 25, § 3.º; 37, XIX; 40, §§ 4.º e 15; 41, § 1.º, III; 43, § 1.º; 45, § 1.º; 49, II; 59, parágrafo único; 68, § 1.º; 79, parágrafo único; 84, XXII; 93, <i>caput</i> ; 121, <i>caput</i> ; 128, § 4.º; 129, VI e VII; 131, <i>caput</i> ; 134, § 1.º; 142, § 1.º; 146; 146-A, <i>caput</i> ; 148; 153, VII; 154, I; 155, § 1.º, III; 155, XII; 156, III; 156, § 3.º; 161; 163; 165, § 9.º; 166, § 6.º; 168; 169, <i>caput</i> , e §§ 2.º, 3.º e 4.º; 184, § 3.º; 192, <i>caput</i> ; 195, § 11; 201, § 1.º; 202, §§ 1.º, 4.º, 5.º e 6.º; 231, § 6.º, todos da CF/88. E arts. 29, §§ 1.º e 2.º; 34, §§ 7.º, 8.º, e 9.º; art. 79; art. 91 do ADCT
Lei ordinária	■ Art. 47: <i>quorum</i> : maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos membros
Lei delegada	■ Art. 68: elaborada pelo Presidente da República, após delegação do Congresso Nacional, mediante resolução
Medida provisória	■ Art. 62: elaborada pelo Presidente da República, tem força de lei. Ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perde a eficácia desde a sua edição se não for convertida em lei no prazo de 60 dias prorrogável, uma única vez, por novos 60 dias , caso não tenha encerrado a

	votação nas duas Casas do Congresso Nacional (cf. art. 62, §§ 3.º e 7.º, na redação determinada pela EC n. 32/2001)
Decreto Legislativo	■ Art. 49: competência exclusiva do Congresso Nacional; art. 62, § 3.º, da CF/88, na redação determinada pela EC n. 32/2001: disciplina os efeitos decorrentes da medida provisória não convertida em lei e que perdeu a sua eficácia desde a sua edição
Resoluções	■ Art. 51: competência privativa da Câmara ■ Art. 52: competência privativa do Senado ■ Art. 68, § 2.º: delegação do CN ao PR para elaborar lei delegada ■ Previsões regimentais: matérias a serem regulamentadas por resoluções do SF, da CD ou do CN EXCEÇÃO: arts. 51, IV, e 52, XIII, as Casas têm iniciativa reservada para o encaminhamento de projeto de lei ordinária para fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços (não se trata, portanto, de projeto de resolução!)

■ 9.15. FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA EXERCIDA PELO LEGISLATIVO E O TRIBUNAL DE CONTAS

Conforme já estudamos, além da função típica de legislar, ao **Legislativo** também foi atribuída função **fiscalizatória**.

Sabemos que, de modo geral, todo **Poder** deverá manter, de forma integrada, sistema de **controle interno de fiscalização** (cf. art. 74, *caput*).

Em relação ao legislativo, além do controle interno (inerente a todo Poder), também realiza **controle externo**, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta (pertencentes ao Executivo, Legislativo e Judiciário) e indireta, levando em consideração a legalidade, legitimidade, economicidade,

aplicação das subvenções e renúncia de receitas (art. 70, *caput*).

A CF/88 consagra, pois, um sistema harmônico, integrado e sistêmico de perfeita convivência entre os **controles internos** de cada Poder e o **controle externo** exercido pelo Legislativo, com o **auxílio** do Tribunal de Contas (art. 74, IV).

Esse sistema de **atuação conjunta** é reforçado pela regra contida no art. 74, § 1.º, na medida em que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência ao TCU, sob pena de **responsabilidade solidária**.

Também deverá prestar contas “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária” (art. 70, parágrafo único, com a redação determinada pela EC n. 19/98).

Portanto, o controle externo será realizado pelo **Congresso Nacional**, auxiliado pelo **Tribunal de Contas**, cujas competências estão expressas no art. 71.

■ 9.15.1. Tribunal de Contas da União

■ 9.15.1.1. Composição e características

O Tribunal de Contas da União, integrado por **9 Ministros**, tem **sede** no **Distrito Federal**, quadro próprio de pessoal e “jurisdição” em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

Malgrado tenha o art. 73 da CF falado em “jurisdição” do Tribunal de Contas, devemos alertar que essa denominação está totalmente **equivocada**. Isso porque o Tribunal de Contas é **órgão técnico** que, além de emitir pareceres, exerce outras atribuições de fiscalização, de controle e, de fato, também a de “julgamento” (tanto é que o Min. Ayres Britto chega a falar em

“**judicatura de contas**” — ADI 4.190). **Porém**, o Tribunal de Contas não exerce jurisdição no sentido próprio da palavra, na medida em que **inexiste** a “definitividade jurisdicional”. É por esse motivo que reputamos não adequada a expressão “jurisdição” contida no art. 73.

No caso de auxílio no *controle externo*, os atos praticados são de **natureza** meramente **administrativa**, podendo ser acatados ou não pelo Legislativo. Em relação às outras atribuições, o Tribunal de Contas também decide **administrativamente**, não produzindo nenhum ato marcado pela definitividade ou fixação do direito no caso concreto, no sentido de afastamento da pretensão resistida. O Tribunal de Contas, portanto, **não é órgão do Poder Judiciário** (não está elencado no art. 92), nem mesmo **do Legislativo**.

Segundo asseverou o Min. Celso de Mello, “os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira, **não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder Legislativo**, de que **não** são órgãos delegatários nem organismos de mero assessoramento técnico. A **competência institucional** dos Tribunais de Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas **traduz emanção que resulta, primariamente, da própria Constituição da República**” (ADI 4.190, j. 10.03.2010).

Como visto e deixando mais claro, o Tribunal de Contas, apesar de autônomo (**autonomia institucional**), sem nenhum vínculo de subordinação ao Legislativo, em determinadas atribuições é auxiliar desse Poder. A fiscalização em si, no caso do *controle externo*, é realizada pelo Legislativo. O Tribunal de Contas, como órgão auxiliar, apenas emite pareceres técnicos nessa hipótese.

Finalmente, é de alertar que as Cortes de Contas (todas elas em seus âmbitos) gozam das prerrogativas da **autonomia** e do **autogoverno**, o que inclui a **iniciativa reservada** para “instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96” da CF/88 (ADI 4.418-MC, j. 06.10.2010; e ADI 1.994, j. 24.05.2006).

Por exemplo, compete ao **TCU**, nos termos do art. 96, propor ao Poder

Legislativo (**iniciativa reservada**) projetos de lei para a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros.

■ 9.15.1.2. *Atribuições constitucionais do TCU*

As atribuições constitucionais estão elencadas no art. 71 da CF/88, de imprescindível leitura para as provas de concursos, destacando-se ser competência do TCU:

■ **apreciar** as **contas** prestadas anualmente pelo **Presidente da República**, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento;

■ **julgar** as **contas** dos **administradores** e **demaís responsáveis** por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

■ **apreciar**, para fins de registro, a **legalidade** dos **atos** de **admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas** as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

■ **realizar**, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, **inspeções e auditorias** de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como demais entidades referidas no inciso II do art. 71;

■ **fiscalizar** as **contas nacionais das empresas supranacionais** de cujo

capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

■ **fiscalizar** a **aplicação de quaisquer recursos repassados pela União** mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

■ **prestar** as **informações** solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

■ **aplicar** aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as **sanções previstas em lei**, como, entre outras cominações, **multa** proporcional ao dano causado ao erário;

■ **assinar prazo** para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato **cumprimento da lei**, se verificada **ilegalidade**;

■ **sustar**, se não atendida, a **execução do ato impugnado**, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

■ **representar** ao Poder competente sobre **irregularidades** ou **abusos apurados**.

Em relação a essas atribuições, estabelece o art. 71, § 4.º, que o TCU encaminhará ao Congresso Nacional, **trimestral** e **anualmente**, um *relatório* de suas atividades.

■ 9.15.1.3. “Apreciar as contas” x “julgar as contas” (art. 71, I e II)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	
■ aprecia as contas	■ Presidente da República

■ julga (administrativamente) as contas	■ dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos ■ daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público
--	--

Devemos deixar bem claro que o **julgamento** das contas dos Chefes dos Executivos não é feito pelo Tribunal de Contas, mas, conforme visto, pelo respectivo **Poder Legislativo**. O Tribunal de Contas apenas **aprecia** as contas, mediante parecer prévio conclusivo, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento.

Nesse sentido, o **art. 49, IX**, da CF/88 estabelece ser competência **exclusiva** do *Congresso Nacional* **julgar** anualmente as **contas** prestadas pelo **Presidente da República** e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Portanto, quem julga as contas é o Poder Legislativo de cada ente federativo. Confira:



Por sua vez, o art. 71, II, dá total autonomia para o TCU **julgar** — e agora percebam que o verbo é “julgar” — e não “apreciar” — as contas dos **administradores e demais responsáveis** por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público **federal** e as **contas** daqueles que **derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade** de que **resulte prejuízo ao erário público**.

Nessa hipótese, assinalou o STF: “... o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do

Poder Legislativo”, tendo o TCU total autonomia (cf. ADI 3.715-MC). Por se tratar de decisão administrativa, naturalmente, o entendimento a ser firmado pelo TCU poderá ser discutido no Judiciário (art. 5.º, XXXV).

■ 9.15.1.4. **Exercício do controle difuso de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas**

Conforme já estudamos no capítulo sobre *controle de constitucionalidade*, destacamos novamente a **Súmula 347 do STF**: “o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”.

Estamos, assim, diante de exemplo de *controle de constitucionalidade posterior* ou *repressivo não jurisdicional*, fugindo ao direito brasileiro que adotou a regra do *judicial review*.

Parece razoável exigir o cumprimento da regra contida no art. 97 da CF/88, que trata da denominada **cláusula de reserva de plenário**, segundo a qual somente pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Devemos alertar, contudo, e conforme já o fizemos, que a subsistência da S. 347 está em discussão [150](#) no STF e vem sendo criticada a partir de decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, em 22.03.2006, ao deferir pedido de medida liminar no **MS 25.888** impetrado pela PETROBRAS, atacando ato do TCU que determinou à impetrante e seus gestores que se abstenham de aplicar o *Regulamento de Procedimento Licitatório Simplificado*, aprovado pelo Dec. n. 2.745/98, devendo ser observadas as regras da Lei n. 8.666/93 (cf. detalhes no *item 6.4.2.4.3*).

■ 9.15.1.5. **Sustação de “atos” e “contratos” administrativos pelo Tribunal de Contas**

A doutrina do *direito administrativo* estabelece, com precisão, a distinção entre **atos** e **contratos administrativos**.

Para Carvalho Filho, o **ato administrativo** pode ser conceituado como “a exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público”. [151](#)

Já o **contrato administrativo** é o “ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza o interesse público”. [152](#)

Portanto, basicamente, pode-se afirmar que, enquanto o **ato administrativo** se caracteriza como manifestação **unilateral** da administração pública, como a *autorização*, a *licença*, a *permissão*, o **contrato administrativo** pressupõe **bilateralidade**, a traduzir obrigação de ambas as partes (muito embora as particularidades e a derrogação do direito comum, em razão do interesse público envolvido) como o *contrato de concessão de serviço público* ou o de *fornecimento*.

Isso posto, cabe observar que, no que concerne ao controle realizado pelo TCU, em razão da distinção entre os dois institutos, o constituinte também criou regras específicas.

Diante de **atos administrativos**, verificando o TCU qualquer ilegalidade, deverá assinalar **prazo** para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, IX).

Findo o prazo e não solucionada a ilegalidade, nos termos do art. 71, X, competirá ao TCU, *no exercício de sua própria competência*, **sustar** a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Em contrapartida, de acordo com o art. 71, § 1.º, no caso de **contrato administrativo**, o ato de sustação será adotado **diretamente** pelo **Congresso Nacional**, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

Contudo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal de Contas da União decidirá a

respeito (art. 71, § 2.º).

Apesar dessa ideia de atuação subsidiária, como assinalou o STF, “... o Tribunal de Contas da União embora não tenha poder para *anular* ou *sustar contratos administrativos* — tem competência, conforme o art. 71, IX, para *determinar* à autoridade administrativa que *promova a anulação do contrato* e, se for o caso, da *licitação* de que se originou”, sob pena de imediata comunicação ao Congresso Nacional, que deverá tomar as medidas cabíveis (MS 23550, j. 04.04.2010).

■ **9.15.1.6. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas?**

Sim.

De acordo com o STF, ao interpretar o art. 71, II, “ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, art. 71, II; Lei 8.443/1992, art. 1.º, I). As **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista**, integrantes da **administração indireta**, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista” (MS 25.092, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 10.11.2005, DJ de 17.03.2006). [153](#)

■ **9.15.1.7. É necessária a observância do devido processo legal em processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas?**

Para responder, transcrevemos a **Súmula Vinculante 3** (30.05.2007): “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade

do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. [154](#)

■ 9.15.1.8. O Tribunal de Contas pode exigir, por si, a quebra de sigilo bancário?

Não.

O STF, no julgamento do [MS 22.801](#), por unanimidade, anulou decisão do TCU “... que obrigava o Banco Central a dar acesso irrestrito a informações protegidas pelo sigilo bancário, constantes do *Sisbacen* (Sistema de Informações do Banco Central). (...) Os ministros reafirmaram que toda e qualquer decisão de quebra de sigilo bancário tem de ser **motivada**, seja ela do **Poder Judiciário** ou do **Poder Legislativo** (no caso por meio das CPIs, acrescente-se). Eles ressaltaram, ainda, que o **TCU**, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, **não** tem **poder** para **decretar quebra de sigilo**. ‘Nós não estamos dizendo que o Banco Central não deva informações ao Poder Legislativo. Ao contrário, nós estamos é afirmando que deve. O que nós estamos aqui decidindo é que uma Câmara do Tribunal de Contas — e o Tribunal de Contas da União **não é o Poder Legislativo** — possa autorizar (ou não) a invasão do *Sisbacen* de forma irrestrita’, explicou o relator da matéria, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito” (*Notícias STF*, 17.12.2007, 16h21).

Isso porque o sigilo bancário busca proteger a **intimidade** e a **vida privada** (art. 5.º, X), devendo eventual mitigação desses direitos fundamentais ser feita com base na Constituição e na ideia de ponderação.

Avançando, nem mesmo a [LC n. 105/2001](#), que trata do assunto, autorizou a mitigação do direito fundamental pelo TCU, o que, em nosso entender, também não poderia, já que estamos diante de **reserva de jurisdição**, como bem decidiu o STF no julgamento do [RE 389.808](#) (j. [15.12.2010](#), por **5 x 4**, *DJE* de 10.05.2011 — cf. discussão nos *itens* 9.8.3.14 e 14.10.8, inclusive a questão particular das CPIs).

Portanto, tanto o TCU como as demais Cortes de Contas, em razão da simetria, **não** têm competência para decretar a quebra do sigilo bancário, mesmo

diante das atividades que desempenham. Nesse sentido:

“EMENTA: (...). 2. Embora as atividades do TCU, por sua natureza, **verificação** de contas e até mesmo o **julgamento** das contas das pessoas enumeradas no artigo 71, II, da Constituição Federal, justifiquem a eventual quebra de sigilo, **não** houve essa determinação na lei específica que tratou do tema, **não cabendo a interpretação extensiva**, mormente porque há princípio constitucional que protege a **intimidade** e a **vida privada**, art. 5.º, X, da Constituição Federal, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário. 3. Ordem concedida para afastar as determinações do acórdão n. 72/96 — TCU — 2.ª Câmara (fl. 31), bem como as penalidades impostas ao impetrante no Acórdão n. 54/97 — TCU — Plenário” (**MS 22.801**, j. 17.12.2007, anterior ao julgamento do *RE 389.808*, que, reafirmando esse entendimento, conforme visto acima, estabeleceu a argumentação no sentido de ser a quebra do sigilo bancário **reserva de jurisdição**). Na mesma linha, cf. **MS 22.934**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.04.2012, 2.ª T., *DJE* de 09.05.2012.

■ 9.15.1.9. Teoria dos poderes implícitos e as atribuições do Tribunal de Contas — possibilidade de concessão de medidas cautelares para assegurar o exercício de suas atribuições

O Min. Celso de Mello, em interessante julgado (cf. *item 3.8*), anotou que a **teoria dos poderes implícitos** decorre de doutrina que, tendo como precedente o célebre caso *McCULLOCH v. MARYLAND* (1819), da Suprema Corte dos Estados Unidos, estabelece que “... **a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos**” (*MS 26.547-MC/DF*, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.05.2007, *DJ* de 29.05.2007).

Acrescentamos que os meios implicitamente decorrentes das atribuições explicitamente estabelecidas devem passar por uma análise de **razoabilidade** e **proporcionalidade**.

Podemos dar como exemplo de aplicação da **teoria dos poderes implícitos** o

reconhecimento, pelo STF, dos poderes do TCU de conceder **medidas cautelares** no exercício de suas atribuições explicitamente fixadas no art. 71 da CF/88 (MS 26.547-MC/DF).

■ **9.15.1.10. Situação jurídica acobertada pela autoridade da coisa julgada pode ser desconstituída por decisão ou ato do Tribunal de Contas?**

Não.

Vem decidindo o STF que, havendo coisa julgada, o instrumento específico para a sua eventual desconstituição, nas hipóteses legais, é a **ação rescisória**.

Assim, mesmo que a matéria acobertada pela autoridade da coisa julgada esteja em discordância com entendimento do próprio STF, não tem o Tribunal de Contas competência para lhe alterar o sentido, seja para suprimir como, também, para conceder vantagens, especialmente diante dos “... postulados da **segurança jurídica**, da **boa-fé objetiva** e da **proteção da confiança**, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito”, que se mostram “impregnadas de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público” (RTJ 191/922):

“EMENTA: Vantagem pecuniária incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público, por força de decisão judicial transitada em julgado: **não pode o Tribunal de Contas, em caso assim, determinar a supressão de tal vantagem**, por isso que a situação jurídica coberta pela **coisa julgada** somente pode ser modificada pela via da **ação rescisória**” (MS 25.460, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.12.2005, Plenário, DJ de 10.02.2006).

“EMENTA: O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557) nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), **ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalecente no âmbito do STF**, pois a ‘res judicata’ em matéria civil só pode ser legitimamente desconstituída mediante **ação rescisória**. Precedentes” (MS 28.150 MC/DF, j. 08.09.2009, DJe de

16.09.2009).

■ 9.15.1.11. **Decisões do Tribunal de Contas com eficácia de título executivo**

De acordo com o art. 71, § 3.º, as decisões do Tribunal de que resulte **imputação de débito** ou **multa** terão eficácia de **título executivo**, devendo a ação ser proposta pelo **ente público beneficiário da condenação**, e não pelo próprio Tribunal de Contas:

“EMENTA: Tribunal de Contas do Estado do Acre. Irregularidades no uso de bens públicos. Condenação patrimonial. Cobrança. Competência. Ente público beneficiário da condenação. Em caso de multa imposta por Tribunal de Contas estadual aos responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos, a ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação do Tribunal de Contas. Precedente” (RE 510.034-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.06.2008, 2.ª Turma, *DJE* de 15.08.2008).

“EMENTA: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Competência para executar suas próprias decisões: **impossibilidade**. Norma permissiva contida na Carta estadual. Inconstitucionalidade. As decisões das Cortes de Contas que impõem **condenação patrimonial** aos responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos **têm eficácia de título executivo** (CF, art. 71, § 3.º). **Não podem, contudo, ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio do Ministério Público, que atua perante ele.** Ausência de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto. **A ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao órgão jurisdicional competente** (no caso, a AGU ou procuradorias competentes, *acrescente-se*). Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local executar suas próprias decisões (CE, art. 68, XI). Competência não contemplada no modelo federal. Declaração de inconstitucionalidade, *incidenter tantum*, por **violação ao princípio da simetria** (CF, art. 75)” (RE 223.037, Rel. Min. Maurício Corrêa, j.

02.05.2002, Plenário, *DJ* de 02.08.2002. No mesmo sentido: **AI 826.676-AgR**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.02.2011, 2.^a Turma, *DJE* de 24.02.2011).

■ **9.15.1.12. Ao decidir, cabe ao Tribunal de Contas manter o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia?**

Não.

O Tribunal de Contas tem atribuição para investigar, independentemente de provocação, podendo agir, portanto, de ofício. Contudo, contribuindo, o art. 74, § 2.º, da CF/88 estabelece ser **parte legítima** para, na forma da lei, **denunciar irregularidades** ou **ilegalidades** perante o TCU:

- qualquer cidadão;
- partido político;
- associação;
- sindicato.

Assim, apresentada a denúncia, o TCU deve manter sigilo sobre a **autoria** dessa denúncia? E sobre o seu **objeto**?

O art. 55, *caput*, e § 1.º, da Lei n. 8.443/92, que dispõe sobre a *Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União* e dá outras providências, **tinha** a seguinte redação:

“Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria.

§ 1.º Ao decidir, caberá ao Tribunal **manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia.**”

A questão chegou a ser analisada pelo **STF**, que declarou, incidentalmente, já que em um caso concreto (controle difuso), a **inconstitucionalidade** da **expressão** constante do § 1.º do art. 55 da *Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União*, Lei n. 8.443/92, **“manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à**

autoria da denúncia”, e do contido no *Regimento Interno do TCU*, que, quanto à **autoria** da denúncia, estabelecia que seria mantido o **sigilo**.

Basicamente, o STF, por maioria, entendeu que o denunciado tem o direito de saber quem está apresentando a denúncia para, eventualmente e se for o caso, exercer o seu direito de resposta, proporcional ao agravo, e buscar, até mesmo, reparação por dano material ou moral por violação à honra e à imagem (art. 5.º, V e X); além do que, apenas em situações excepcionais é vedado o direito de se obter informações dos órgãos públicos (art. 5.º, XXXIII) (cf. **MS 24.405**, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 03.12.2003, **Plenário**, *DJ* de 23.04.2004).

O Min. Gilmar Mendes, em seu voto, de maneira bastante firme, chega a afirmar que a não identificação daquele que leva a informação dos fatos pode caracterizar práticas abusivas ou até de perseguição, seja por quem denuncia ou até, eventualmente, pelo próprio órgão da administração pública.

E arremata: “... configura ‘**covardia republicana**’ usar órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Receita Federal a serviço de partido político. É uma das coisas mais **inescrupulosas** de que se tem notícia. Violenta a ideia de igualdade de oportunidade, violenta aquilo que é mais relevante na democracia”.

A partir do julgamento do caso concreto, cumprindo o art. 52, X, o Senado Federal, nos termos da **Resolução n. 16/2006**, *suspendeu a execução* da expressão “**manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia**” constante do § 1.º do art. 55 da *Lei Federal n. 8.443/92* e do contido no *Regimento Interno do Tribunal de Contas da União*, quanto à **manutenção do sigilo em relação à autoria de denúncia**, em virtude da declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do STF, nos autos do referido MS 24.405.

Dessa forma, as investigações pelo TCU poderão ser de ofício ou por denúncia, devendo, ao final do procedimento, ser revelado o seu objeto, bem como a sua autoria.

Para finalizar, um ponto precisa ser mais bem estudado pelo STF e diz respeito à **denúncia anônima**, que, diante do entendimento fixado pelo STF de

o denunciante formal ser identificado, deve tender a aumentar, já que muitos temerão alguma represália ou retaliação.

Além daquele que age com covardia e se utiliza dos órgãos para implementar disputas políticas, não podemos nos esquecer do cidadão honesto, correto, que, sem nenhuma outra intenção, simplesmente quer levar ao conhecimento do poder público alguma irregularidade, mas teme a represália.

Em caso similar, mas envolvendo a prática de **crime**, o STF admitiu a denúncia anônima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela.

Segundo o Min. Toffoli, a partir do julgamento do HC 84.827/TO (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.08.2007), de fato, o STF “... assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se a orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar *diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros*, para, só então, iniciar as investigações. 2. No caso concreto, ainda sem instaurar inquérito policial, policiais civis diligenciaram no sentido de apurar a eventual existência de irregularidades cartorárias que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange à realização de **diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito**” (HC 98.345, j. 16.06.2010, **1.ª Turma** — e observe-se que não foi pelo *Pleno*).

O Min. Ricardo Lewandowski, em referido julgamento, chegou a estimular a ideia da “denúncia anônima” no sentido de deflagrar **iniciação prévia**, sem, ainda, a abertura de inquérito policial, incentivando a *cidadania participativa no combate ao crime* e, assim, o “direito à proteção contra eventual represália ou retaliação”.

O Min. Celso de Mello, outrossim, ao analisar a **denúncia anônima**, que realmente encontra limites no art. 5.º, IV, que **veda o anonimato**, chegou a

apontar o exato sentido dessa garantia constitucional: “... nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por **denúncia anônima** (‘disque-denúncia’, p. ex.), adote **medidas informais** destinadas a apurar, **previamente**, em **averiguação sumária**, ‘**com prudência e discrição**’, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o **objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados**, em ordem a promover, então, **em caso positivo**, a **formal instauração da ‘persecutio criminis’**, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas” (HC 100.042-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, *DJe* de 08.10.2009 e, originariamente, em seu voto no Inq. 1.957, j. 11.05.2005 — grifamos).

Portanto, diante de todas essas manifestações, apesar do entendimento do STF externado no MS 24.405 no sentido de, ao decidir, estar proibido o TCU de **manter o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia**, parece-nos que a **denúncia anônima** poderá, também, ser “aproveitada” pelo TCU no cumprimento de sua nobre missão constitucional.

Partindo da *denúncia anônima*, o TCU poderá adotar, parafraseando a decisão do Min. Celso de Mello, aqui adaptada, **medidas informais** destinadas a apurar, **previamente**, em **averiguação sumária**, “**com prudência e discrição**”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude ou ilegalidade, desde que o faça com o **objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados**, em ordem a promover, então, **em caso positivo**, a formal instauração do **procedimento administrativo**, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas (**matéria pendente de aprofundamento pelo STF**, especialmente pelo **Pleno**).

Esse entendimento fica reforçado no sentido de que, conforme visto, o TCU atua não somente por provocação, mas também de **ofício**, no cumprimento de suas atribuições constitucionais.

Tal proposta de interpretação encontra fundamento, ainda, no art. 13, item 2, da **Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção**, [155](#) ao estabelecer que “cada Estado-Parte adotará medidas apropriadas para garantir que o público

tenha conhecimento dos órgãos pertinentes de luta contra a **corrupção** mencionados na presente Convenção, e facilitará o acesso a tais órgãos, quando proceder, para a **denúncia, inclusive anônima**, de quaisquer incidentes que possam ser considerados constitutivos de um delito qualificado de acordo com a presente Convenção”.

■ 9.15.1.13. *Ministros do Tribunal de Contas da União*

■ **requisitos:** ser brasileiro (nato ou naturalizado); ter mais de **35** e menos de **65** anos de idade; idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública e mais de **10** anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados;

■ **escolha:** os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados após escolha, que se dará da seguinte forma:

a) 3 (1/3 dos 9) pelo **Presidente da República**, com aprovação do Senado Federal pelo *quorum* da maioria simples (art. 47 da CF/88), sendo 2 alternadamente dentre **auditores** e **membros do Ministério Público junto ao Tribunal**, [156](#) indicados em lista tríplice;

b) 6 (2/3 dos 9) pelo **Congresso Nacional** (art. 73, § 2.º, I e II).

Assim, embora tenha enfrentado o tema de modo definitivo apenas para o TCE (*vide* [S. 653/STF](#)), [157](#) a tendência no STF no que respeita ao **TCU** parece-nos ser a seguinte: dos **9** Ministros:

a) 3 (1/3 dos 9) são escolhidos pelo Presidente da República. Desses três, **1** será de sua livre escolha, **1** dentre auditores (indicados em lista tríplice pelo TCU) e **1** dentre membros do MP junto ao TCU (também a ser escolhido pelo Presidente dentre aqueles da lista tríplice a ser enviada pelo TCU), destacando-se ter o Presidente da República, nessas hipóteses de lista tríplice, total **discricionariedade** para escolher 1 dos 3;

b) 6 (2/3 dos 9), quais sejam, **6** dos **9**, serão indicados pelo Congresso Nacional, nos termos dos Decretos Legislativos ns. 6/93 e 18/94.

Em sede de julgamento liminar, confirmada no julgamento de mérito, o STF entendeu que, à medida que forem abrindo as vagas, aquelas de **origem** deverão ser **preservadas** (por exemplo, aposentando um membro do TCU proveniente do MP, deverá ser indicado um novo membro dentre aqueles da lista tríplice integrada por membros do MP junto ao TCU). Não se trata de mero critério rotativo de escolha, como prescrevem o inciso III do art. 105 da Lei n. 8.443/92 e o inciso III do art. 280 do Regimento Interno do TCU. Trata-se, em verdade, de **composição constitucional definida, fixa e expressa** no art. 73, § 2.º, I e II, da CF; [158](#)

■ **nomeação:** pelo Presidente da República, na dicção do art. 84, XV, observadas as regras de escolha (composição) prescritas no art. 73;

■ **garantias:** os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 (cf. no item 11.4.2 as discussões sobre a **EC n. 88/2015**);

■ **auditores:** [159](#) de acordo com o art. 73, § 4.º, da CF/88, o **auditor**, quando em **substituição** a **Ministro**, terá as mesmas garantias e impedimentos do **titular** e, quando no exercício das **demais atribuições da judicatura**, as de **juiz de Tribunal Regional Federal**.

■ 9.15.2. Distinção entre a atuação do TCU e da CGU: inexistência de invasão de atribuições. Auxílio no controle externo (TCU) x controle interno (CGU) — perfeita convivência

Inicialmente, com base na *MP n. 2.143-31/2001*, em 02.04.2001, foi criada a então denominada *Corregedoria-Geral da União (CGU)*, órgão vinculado diretamente à Presidência da República e que, originariamente, tinha por objetivo combater a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público, no âmbito do Poder Executivo Federal. [160](#)

O *Decreto n. 4.177/2002* integrou a *Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)* e a *Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI)* à estrutura da

então *Corregedoria-Geral da União*, transferindo-lhe, também, as competências de *Ouvidoria-Geral*, à época vinculadas ao Ministério da Justiça.

A MP n. 103/2003, por sua vez, convertida na **Lei n. 10.683/2003**, alterou a denominação do órgão para **Controladoria-Geral da União (CGU)**, passando a denominar o seu titular *Ministro de Estado do Controle e da Transparência*.

O Decreto n. 8.109/2013, por sua vez, aprovou a *Estrutura Regimental* e o *Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão* e das *Funções Gratificadas da Controladoria-Geral da União* e remanejou cargos em comissão.

Assim, a **Controladoria-Geral da União (CGU)** integra a Presidência da República e, de acordo com o art. 17, *caput*, da Lei n. 10.683/2003, compete-lhe assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à **defesa do patrimônio público**, ao **controle interno**, à **auditoria pública**, à **correição**, à **prevenção** e ao **combate à corrupção**, às **atividades de ouvidoria** e ao **incremento da transparência da gestão** no âmbito da **administração pública federal**.

Dessa forma, enquanto o TCU é órgão **auxiliar** do **Congresso Nacional** na realização do **controle externo**, a **CGU** é órgão auxiliar do **Executivo Federal** (Presidente da República) no cumprimento de sua missão constitucional de **controle interno** do patrimônio da União e fiscalização dos recursos públicos federais.

Isso posto, trazemos questão interessante que surgiu no STF em relação aos poderes e competências da CGU.

Trata-se do **RMS 25.943/DF** (j. 24.11.2010), interposto contra ato do *Ministro de Estado do Controle e da Transparência* que, por sorteio, diante da impossibilidade de se analisar todos, selecionou Municípios para auditar e fiscalizar a destinação dos recursos públicos federais, em razão de repasse.

No caso concreto, foi sustentado que, em verdade, a CGU não poderia auditar as contas do Município, já que seria atribuição exclusiva do TCU, nos termos do art. 71, VI, que estabelece ser competência do *Tribunal de Contas da União* fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

Contudo, o STF, por maioria, entendeu ser perfeitamente possível a convivência do **controle externo**, exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU, com o **controle interno** de cada Poder, sendo, no caso do Executivo federal, implementado com o auxílio da **CGU**, órgão criado com o objetivo de otimizar o cumprimento do art. 70 da CF/88 (cf. *Inf. 610/STF*).

■ 9.15.3. Tribunais de Contas Estaduais e Tribunal de Contas do Distrito Federal

As normas estabelecidas para o Tribunal de Contas da União (TCU) aplicam-se, no que couber e por simetria, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal (art. 75, *caput*).

As regras sobre os Tribunais de Contas Estaduais deverão estar previstas na Constituição Estadual, com expressa menção de que o número de **Conselheiros** (e aqui não se fala em Ministros) deverá ser de **7**, regra essa que deverá ser seguida, também, no âmbito do DF.

Nos termos da **Súmula 653** do STF, “no Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, **quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual**, cabendo a este indicar **um** dentre **auditores** e **outro** dentre **membros do MP especial**, e um **terceiro** à sua **livre escolha**”, fazendo interpretação do art. 75, *caput*, que estabeleceu o dever de observância de sua composição, **no que couber**, em relação às regras do TCU, que é composto por 9, e não 7 integrantes.

Convém lembrar que, segundo o art. 235, III, da CF/88, nos **10 primeiros anos da criação de novo Estado, o Tribunal de Contas será inicialmente formado por 3 membros**, nomeados pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber.

Em relação a esse bem delimitado processo de indicações, conforme

estabeleceu o STF, “a determinação acerca de qual dos **poderes** tem competência para fazer a escolha dos membros dos tribunais de contas estaduais deve **preceder à escolha da clientela** sobre a qual recairá a nomeação” (ADI 3.688, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 11.06.2007, Plenário, DJ de 24.08.2007. No mesmo sentido: ADI 374, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.03.2012, Plenário; ADI 1.957, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1.º.09.2010, Plenário).

Assim, das 7 vagas, 4 serão escolhidas pelo Poder Legislativo e 3 pelo Poder Executivo (escolha fundada na **separação de poderes**). Trata-se de verdadeiras “**cadeiras cativas**” no sentido de que, se a vaga que **surge** for de indicação de um Poder, o outro não poderá proceder à escolha para aquela “cadeira” (Joaquim Barbosa em seu voto na ADI 3.688). Só então, superada essa fase, será feita a indicação por cada Poder. A Assembleia Legislativa do Estado escolhe livremente (desde que preenchidos os requisitos) e o Governador do Estado escolhe um entre auditores, o outro entre membros do MP especial e um terceiro de livre escolha (nesse caso, como disse o Min. Marco Aurélio, a escolha é “motivada pela necessidade de conferir *expertise* e independência ao órgão” — RE 717.424).

Esse entendimento no sentido de **prevalência da regra constitucional de escolhas entre os Poderes** é tão firme na jurisprudência da Corte que tem sido reconhecida a possibilidade de o Tribunal de Contas Estadual, nesse **período de transição** pós-CF/88 (já que, no regime anterior, a escolha era feita somente pelo Executivo), **poder ficar sem a presença de membro do Ministério Público de Contas** até que surja a vaga entre os que foram escolhidos pelo Executivo, não podendo retirar o direito de escolha pertencente ao Legislativo.

Nesse sentido, a atual composição do STF se posicionou, muito embora em votação apertada (**5 x 4** — não votaram dois Ministros: a) Min. Roberto Barroso por ter declarado suspeição; b) Min. Joaquim Barbosa, aposentado e sem a indicação de novo Ministro para a sua vaga), no julgamento do **RE 717.424** (j. 21.08.2014).

Como disse o Min. Marco Aurélio em seu voto, “o Supremo, enfrentando o tema em diversos julgamentos, proclamou que **prevalece a regra**

constitucional de divisão proporcional das indicações entre os Poderes Legislativo e Executivo, e ao inerente critério da ‘vaga cativa’, sobre a obrigatória indicação de clientelas específicas pelos Governadores. O Tribunal definiu tratar-se de **regras sucessivas**: *primeiro*, observa-se a proporção de escolhas entre os poderes para, apenas *então*, cumprirem-se os critérios impostos ao Executivo, não havendo exceção a tal sistemática, **nem mesmo em razão da ausência de membro do Ministério Público Especial.** Isso significa que o atendimento da norma quanto à distribuição de cadeiras em favor de auditores e do Ministério Público somente pode ocorrer quando **surgida vaga pertencente ao Executivo**, não se mostrando legítimo sacrifício ao momento e ao espaço de escolha do Legislativo. Nem mesmo a necessidade de equacionar regimes de transição, segundo a jurisprudência do Supremo, justifica o abandono dessa prioridade” (fls. 9 do acórdão).

Ainda, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, conjugando-se o art. 75, *caput*, com o art. 73, § 3.º, da CF/88, os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Estados e do DF terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Desembargadores dos TJs**, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 (ADI 4.190, j. 10.03.2010).

Finalmente, já alertamos, as Cortes de Contas (todas elas em seus âmbitos) gozam das prerrogativas da **autonomia** e do **autogoverno**, o que inclui a **iniciativa reservada** para “instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96” da CF/88 (ADI 4.418-MC, j. 06.10.2010; e ADI 1.994, j. 24.05.2006).

Assim, por exemplo, compete ao Tribunal de Contas do Estado (art. 96) propor ao respectivo Poder Legislativo (**iniciativa reservada**) projetos de lei para criação e extinção de cargos, remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como fixação do subsídio de seus membros.

■ 9.15.4. Tribunais de Contas Municipais

De acordo com o art. 75, *caput*, da CF/88, as normas estabelecidas para o Tribunal de Contas da União (TCU) também se aplicam, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

A CF/88, em seu art. 31, § 4.º, veda a **criação** de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais. No entanto, e de maneira aparentemente paradoxal, no § 1.º do art. 31 dispõe que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o **auxílio** dos Tribunais de Contas dos Estados ou do **Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver**.

Daí, a única conclusão a que podemos chegar é que, após a promulgação da CF/88, veda-se a criação de Tribunais de Contas Municipais. No entanto, os que existiam à época deverão permanecer em funcionamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Tribunais de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro (constituído em 23.10.1980) e de São Paulo (TCM/SP, criado pela Lei n. 7.213, de 20.11.1968, composto, a título de curiosidade, por **5** Conselheiros).

Os Tribunais de Contas Municipais (onde houver) e Estaduais também auxiliarão o Legislativo (Câmara Municipal) a exercer o controle das contas do Executivo.

Na hipótese de auxílio a ser prestado à Câmara dos Vereadores pelo Tribunal de Contas Estadual, o STF vem considerando a possibilidade de ser instituído no Município um Tribunal de Contas que, embora atue naquele Município específico como Tribunal de Contas, é órgão Estadual. Nesse sentido:

“EMENTA: Municípios e Tribunais de Contas. A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4.º), mas permite que os **Estados-membros**, mediante **autônoma deliberação, instituem órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios** (RTJ 135/457, Rel. Min. Octavio Gallotti — ADI 445/DF, Rel. Min. Néri da Silveira), incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle externo (CF, art. 31, § 1.º). Esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios — embora qualificados como **órgãos estaduais**

(CF, art. 31, § 1.º) — **atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores**. A prestação de contas desses Tribunais de Contas dos Municípios, que **são órgãos estaduais** (CF, art. 31, § 1.º), há de se fazer, por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio Estado, e não perante a Assembleia Legislativa do Estado-membro. Prevalência, na espécie, da competência genérica do Tribunal de Contas do Estado (CF, art. 71, II, c/c o art. 75)” (ADI 687, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.02.95, Plenário, DJ de 10.02.2006).

O controle externo das contas do Prefeito será realizado pela **Câmara Municipal**, auxiliada pelo Tribunal de Contas Municipal — TCM (onde houver) ou pelo Tribunal de Contas Estadual (se inexistir, naquele Município, o municipal) ou por eventual Tribunal de Contas **do** Município, instituído para funcionar naquela localidade, apesar de órgão estadual.

O Tribunal de Contas (art. 31, § 2.º) emitirá **parecer técnico prévio** sobre as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, podendo ser rejeitado pela Câmara Municipal pelo voto de **2/3** de seus membros.

Aqui, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas no controle das contas do **Prefeito** é muito particular e diferente da regra para o controle das contas dos *Governadores* e do *Presidente da República*.

Isso porque, no âmbito do controle das contas municipais, a presunção é pela validade do parecer, da sua natural prevalência, já que, para não produzir efeitos, terá de ser derrubado pelo *quorum* qualificado de 2/3 de seus membros.

Fazendo o confronto, em relação à apreciação das contas dos Governadores e do Presidente da República os pareceres serão, em contrapartida, meramente **opinativos**.

■ 9.15.5. Ministério Público Especial (art. 130)

E os membros do MP junto ao Tribunal de Contas devem pertencer a carreira específica ou podem ser “aproveitados” da carreira do Ministério Público?

O STF já decidiu que “... somente o **Ministério Público especial** tem

legitimidade para atuar junto às Cortes de Contas dos Estados-membros, e que a organização e a composição destas se submetem ao modelo jurídico estabelecido na Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Estados-membros...” (ADI 3.192/ES, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.05.2006, cf. Inf. 428/STF). Assim, não se admitiu que membros do MP estadual fossem “aproveitados” para atuar junto ao TCE. Reforçou-se a ideia de estabelecimento de carreira específica do **MP especial** junto ao Tribunal de Contas.

A matéria está bastante pacificada;¹⁶¹ portanto, pode-se afirmar que os Procuradores das Cortes de Contas são a elas ligados **administrativamente**, não podendo aproveitar os membros do **Ministério Público comum**.

Em interessante julgado, o STF entendeu que “a conversão automática dos cargos de Procurador do Tribunal de Contas dos Municípios para os de Procurador de Justiça — cuja investidura depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos” ofende os arts. 73, § 2.º, I; 130 e 37, II, da CF/88 (ADI 3.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2008, DJE de 11.04.2008).

Interessante destacar, ainda, que, no julgamento da *Consulta n. 0.00.000.000843/2013-39*, formulada pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), o **Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)** entendeu que o **Ministério Público de Contas (MPC)** e seus **membros** estão sujeitos ao seu controle administrativo, financeiro e disciplinar:

“Consulta respondida positivamente para reconhecer ao Ministério Público de Contas a **natureza jurídica de órgão do Ministério Público brasileiro** e, em consequência, a competência do CNMP para zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos respectivos membros e pela garantia da autonomia administrativa e financeira das unidades, controlando os atos já praticados de forma independente em seu âmbito, e adotando medidas tendentes a consolidar a parcela de autonomia de que ainda carecem tais órgãos” (j. 07.08.2013 — *tema pendente de análise pelo STF*).

Apesar da resposta dada pelo CNMP, muito embora tenha sido afirmado que

o MPC apresenta natureza jurídica de órgão do MP brasileiro, não poderá haver o aproveitamento de membros de uma carreira na outra, como já vinha decidindo o STF.

A discussão sobre a **natureza jurídica** deverá ser enfrentada pelo STF, destacando que o **art. 130 da CF** estabelece que aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições da Seção I, do Capítulo IV, do Título IV (arts. 127 a 129), pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura, **apesar de o art. 128 não inserir em sua abrangência, ao menos formalmente, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPC) (tema pendente).**

Nesse contexto, a partir da decisão acima referida, foi encaminhada ao Senado Federal a **PEC n. 42/2013**, com o objetivo de “incluir o MPC e seus Membros na ‘jurisdição’ do Conselho Nacional de Justiça — CNMP”.

CUIDADO: respondendo a Ofício encaminhado pelo relator da matéria no Senado Federal, o CNMP apresentou a **Nota Técnica n. 5/2015** revendo o seu posicionamento e só admitindo a competência do CNMP se houver na referida PEC (e, portanto, a modificação da Constituição) a **inclusão do MPC no art. 128**, deixando claro tratar-se de órgão do Ministério Público e, assim, sujeito ao controle do Conselho (cf. *item 12.2.11*).

■ 9.16. QUESTÕES

■ 9.16.1. Do Poder Legislativo — Aspectos gerais (estrutura, atribuições, reuniões, comissões, imunidades, incompatibilidades e impedimentos, perda do mandato)

1. (OAB/103.º) O Poder Legislativo dos Estados é constituído sob o regime: 162

- a) bicameral;
- b) unicameral;
- c) pluricameral;
- d) multicameral.

2. (MP/81.º) Marque, dentre as opções que se seguem, a que não contém afirmativa incorreta sobre as comissões parlamentares de inquérito:

- a) possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e podem ser criadas mediante requerimento de qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- b) possuem poderes de investigação próprios das autoridades policiais e podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um quarto de seus membros;
- c) possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros;
- d) podem ser criadas por determinação da presidência de qualquer das Casas do Congresso Nacional ou por requerimento de um quarto de seus membros para a apuração de fato determinado;
- e) podem ser criadas, independentemente de requerimento de qualquer parlamentar, mediante determinação da Mesa de qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou por solicitação do Presidente da República, para a apuração de fato determinado.

3. (OAB/111.º) As Comissões Parlamentares de Inquérito estão constitucionalmente autorizadas a:

- a) determinar a prisão preventiva dos infratores, nos termos da lei processual penal, pois possuem os mesmos poderes da autoridade judicial;
- b) solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, pois possuem os mesmos poderes investigatórios da autoridade judicial;
- c) determinar a quebra de sigilo bancário, pois possuem os mesmos poderes investigatórios da autoridade policial;
- d) promover a responsabilização civil e criminal dos infratores.

4. (Agente Legislativo de Serviços Técnicos e Administrativos ALESP — FCC 2010) As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento

- a) de, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia Legislativa.
- b) da maioria simples dos membros da Assembleia Legislativa.

- c) de, no mínimo, três quintos dos membros da Assembleia Legislativa.
- d) da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.
- e) de, no mínimo, dois terços dos membros da Assembleia Legislativa.

5. (Promotor de Justiça/TO — CESPE/UnB/2012) Assinale a opção correta com referência às CPIs:

- a) A testemunha ou indiciado, quando convocado, não é obrigado a comparecer à CPI e não precisa responder às perguntas que possam incriminá-lo, em razão do seu direito constitucional ao silêncio e a não autoincriminação.
- b) O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que impliquem a revelação das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa.
- c) Por constituírem exercício da função político-administrativa do Poder Legislativo, as CPIs, mediante decisões fundamentadas, podem impor sanções administrativas aos infratores.
- d) É vedada a ampliação da atuação de CPI para além da finalidade para a qual ela tenha sido criada, ainda que sejam descobertos elementos novos não previstos originariamente no ato de instauração dessa CPI.
- e) Insere-se na competência da CPI a determinação da quebra de sigilo da comunicação telefônica, sendo-lhe vedado, no entanto, requerer a quebra de registros telefônicos pretéritos, isto é, a lista de ligações efetuadas e recebidas pelo investigado durante determinado período de tempo já transcorrido.

6. (Procurador da AL/ES — CESPE/UnB/2011) No que se refere ao Poder Legislativo, assinale a opção correta:

- a) Segundo posicionamento do STF, por força do princípio da simetria, as CPIs estaduais têm poderes para quebrar sigilo bancário de seus investigados, independentemente de ordem judicial.
- b) O mandato dos membros das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, regra, segundo o STF, de reprodução obrigatória para os estados-membros no âmbito das respectivas assembleias legislativas.
- c) A existência de procedimento penal investigatório em trâmite no Poder Judiciário impede

a realização de atividade investigatória por CPI quando os objetos são correlatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

- d) O STF considera constitucional regra estabelecida no âmbito da assembleia legislativa de estado que reconheça como requisito para a instauração de CPI, além de um terço de assinaturas dos membros, a aprovação do pedido pela maioria absoluta do plenário da assembleia legislativa.
- e) Em caso de urgência ou interesse público relevante, a convocação extraordinária do Congresso Nacional poderá decorrer de requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, hipótese em que será dispensada a aprovação do pedido de convocação pelos membros do Congresso Nacional, já que a própria maioria dos referidos membros a terá solicitado.

7. (Analista Ministerial — MP/PI — Área Administrativa — CESPE/UnB/2012) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsequente:

As comissões parlamentares de inquérito podem pedir a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico e determinar a busca e apreensão domiciliar com base nos poderes de investigação que lhes foram conferidos pela CF.

8. (OAB/118.º/SP) O Deputado Federal que, após sua diplomação, incorre na prática de homicídio qualificado:

- a) poderá ser processado, desde que haja licença prévia concedida pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados;
- b) poderá ser processado, desde que haja licença prévia concedida pela maioria dos membros do Congresso Nacional;
- c) não poderá ser processado, pois goza de imunidade material;
- d) poderá ser processado, independentemente de licença da Câmara dos Deputados.

9. (X Concurso Juiz do Trabalho — 14.ª Região — Rondônia e Acre) Determinado Estado da Federação tem representação de 68 Deputados na Câmara dos Deputados. De acordo com as disposições constitucionais sobre a matéria, quantos Deputados à Assembleia Legislativa haverá?

- a) 96 deputados;
- b) 84 deputados;
- c) 92 deputados;
- d) 76 deputados;

e) 70 deputados.

10. (Agente Administrativo — PRF — CESPE/UnB/2012) Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item subsecutivo:

Um estado da Federação que possua 51 deputados federais possuirá, necessariamente, 76 deputados estaduais.

11. (TJMG — EJEJF/2008) As imunidades parlamentares — material e formal — constituem garantia significativa para o exercício do mandato concedido pelo povo aos integrantes do Poder Legislativo:

- a) As imunidades podem ser objeto de renúncia.
- b) A imunidade parlamentar material obsta a propositura de ação penal ou indenizatória contra o membro do Poder Legislativo pelas opiniões, palavras e votos que proferir e exige relação de pertinência com o exercício da função.
- c) A imunidade parlamentar formal somente garante ao integrante do Poder Legislativo a impossibilidade de ser ou de permanecer preso.
- d) A imunidade parlamentar material será aplicável somente nos casos em que a manifestação do pensamento ocorrer dentro do recinto legislativo.

12. (Procurador do Estado do Amazonas/FCC/2010) O Deputado Federal ou Senador pego em flagrante durante prática de crime (questão adaptada — a original apresenta 5 alternativas):

- a) poderá ter sua prisão decretada, independentemente de o crime ser inafiançável ou não.
- b) poderá ter sua prisão decretada, apenas se o crime for inafiançável.
- c) não poderá ser denunciado judicialmente, salvo mediante prévia autorização da Casa legislativa respectiva.
- d) poderá ser denunciado judicialmente ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de autorização da Casa legislativa respectiva.

13. (50.º Concurso para MP/MG — 2010) Consoante o que dispõe o texto constitucional de 1988 em vigor, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa do Poder Executivo, observado o que dispõem os arts. 37, IX, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I.

- b) Os subsídios dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa do Poder Executivo, observado o que dispõem os arts. 37, IX, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I.
- c) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição.
- d) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, por lei de iniciativa do Poder Executivo, observado o que dispõe a Constituição.

14. (Exame da OAB Unificado 2010.2 — FGV) O Congresso Nacional e suas respectivas Casas se reúnem anualmente para a atividade legislativa. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.

- a) Legislatura: o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1.º de agosto a 22 de dezembro.
- b) Sessão legislativa: os quatro anos equivalentes ao mandato dos parlamentares.
- c) Sessão conjunta: a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal destinada, por exemplo, a conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar.
- d) Sessão extraordinária: a que ocorre por convocação ou do Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos Deputados ou do Presidente da República e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas para, excepcionalmente, inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras.

15. (Câmara dos Deputados — Analista Legislativo — CESPE/UnB/2012) A respeito das competências do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, julgue o item subsequente:

É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas.

16. (Agente Administrativo — PRF — CESPE/UnB/2012) Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário:

Cada um dos vinte e seis estados da Federação mais o Distrito Federal elegem três senadores, totalizando oitenta e um senadores com mandato de oito anos, havendo para cada senador dois suplentes.

17. (Promotor de Justiça — MP/AL — FCC/2012) A competência para apreciar atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão é

- a) do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República.
- b) exclusiva do Congresso Nacional.
- c) privativa da Câmara dos Deputados.
- d) privativa do Senado Federal.
- e) privativa do Presidente da República.

■ 9.16.2. Tribunal de Contas

1. (OAB/106.º) O controle externo das contas do Chefe do Poder Executivo é função:

- a) das Câmaras Municipais, nos Municípios, com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas;
- b) dos Tribunais de Contas, sujeito à prévia apreciação do Poder Legislativo;
- c) exclusiva do Poder Judiciário;
- d) de natureza jurisdicional, em face de caber ao Congresso Nacional suscitar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar.

2. (OAB/111.º) Um cidadão, sabendo que o prefeito de sua cidade está cometendo irregularidades ou ilegalidades na administração do dinheiro público:

- a) deve fazer parte de uma associação ou sindicato para ter legitimidade para denunciá-lo perante o Tribunal de Contas competente;
- b) pode apenas denunciá-lo perante o Ministério Público;
- c) pode denunciá-lo perante o Tribunal de Contas competente;
- d) não terá legitimidade para denunciá-lo perante o Tribunal de Contas.

3. (117.º/OAB/SP) São julgadas pelo Tribunal de Contas da União as contas:

- a) do governador do Distrito Federal;
- b) do Presidente da República;
- c) dos governadores de Estado;
- d) dos superintendentes de autarquias federais.

4. (Magistratura/174.º) Ante a expressão “julgar as contas” (art. 71, II, da Constituição Federal), as decisões dos Tribunais de Contas são:

- a) jurisdicionais;
- b) homologatórias;
- c) políticas;
- d) administrativas.

5. (OAB/119.º) Tem o Tribunal de Contas da União competência para punir particulares?

- a) Sim, em casos de prestação de contas em que venha a concorrer para a prática de atos danosos ao erário;
- b) Não, porque a relação jurídica que se impõe entre a União e um particular é sempre de direito privado, e não de direito público;
- c) Sim, desde que ajuíze ação civil indenizatória;
- d) Não, porque o TCU só tem tutela hierárquica sobre os servidores públicos.

6. (Advogado Júnior Petrobras — Cesgranrio/2008) Segundo disposição constitucional expressa, as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de sua competência de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, das quais resulte imputação de débito ou multa,

- a) terão eficácia de título executivo.
- b) deverão ser validadas pelo Congresso Nacional.
- c) serão encaminhadas ao Congresso Nacional para as providências relativas a sua cobrança.
- d) serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências relativas a sua cobrança.
- e) darão ensejo à propositura de processo de conhecimento perante o Poder Judiciário, como etapa necessária à cobrança.

7. (Analista Judiciário TRT 9.ª R. — Administrativa — FCC 2010) No que diz respeito à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é certo que:

- a) as Constituições estaduais e as leis orgânicas dos Municípios disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por onze Conselheiros.
- b) o sindicato também é parte legítima, na forma da lei, para denunciar irregularidades ou

ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

- c) compete ao Tribunal de Contas da União sustar a execução de ato impugnado, comunicando a decisão ao Poder Executivo e ao juiz competente.
- d) as decisões dos Tribunais de Contas que resultem em imputação de débito ou multa não têm eficácia de título executivo por ser prerrogativa do Poder Judiciário.
- e) o Tribunal de Contas da União encaminhará para a Câmara dos Deputados, semestralmente, o relatório de suas atividades e anualmente ao Ministério Público.

8. (Analista Técnico da SUSEP — ESAF 2010) As atribuições do Tribunal de Contas da União têm assento constitucional e é possível constatar alguns tipos de fiscalização a serem desempenhadas por aquela Corte de Contas. É correto afirmar que não é tipo de fiscalização:

- a) o controle da legitimidade.
- b) o controle da legalidade.
- c) o controle de conveniência política e oportunidade administrativa.
- d) o controle de resultados, de cumprimento de programa de trabalho e de metas.
- e) o controle de fidelidade funcional dos agentes da Administração responsável por bens e valores públicos.

9. (Técnico Judiciário — área administrativa — TRT/9.^a Região) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e de suas entidades, exercida pelo Congresso Nacional e por parte de cada Poder NÃO abrange aspectos de

- a) economicidade.
- b) aplicação de subvenções.
- c) instituição de tributos.
- d) legitimidade.
- e) renúncia de receitas.

10. (Procurador do Estado do Amazonas/FCC/2010) Nos termos da Constituição Federal, NÃO se encontra entre as atribuições do Tribunal de Contas da União:

- a) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração indireta.
- b) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

- c) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidades de contas, as sanções previstas em lei.
- d) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) sustar, independentemente de decisão do Congresso Nacional, a execução de contrato ilegalmente firmado pela administração direta ou indireta.

11. (Auxiliar da Fiscalização Financeira/TCSP — FCC/2010) As decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa:

- a) só terão eficácia se confirmadas em posterior processo administrativo.
- b) não terão qualquer eficácia, porque produzidas unilateralmente.
- c) constituirão mero início de prova para propositura de ação de cobrança.
- d) não terão qualquer eficácia, porque possuem mero conteúdo declaratório.
- e) terão eficácia de título executivo.

12. (Auxiliar da Fiscalização Financeira/TCSP — FCC/2010) Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens

- a) dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
- b) dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- c) do Presidente da República.
- d) dos Ministros de Estado.
- e) dos membros do Congresso Nacional.

13. (Procurador Jurídico da USP/FUVEST — 2011) Sobre o regime constitucional aplicável aos Tribunais de Contas, considere as assertivas abaixo:

- I) Aos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados é assegurada a garantia da vitaliciedade, sendo vedado decretar-lhes a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado.
- II) As contas do Prefeito submetem-se a parecer prévio do Tribunal de Contas, que, diferentemente do exame das contas do Governador e do Presidente da República, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

III) A exemplo dos Tribunais Superiores, o texto constitucional assegura iniciativa legislativa ao Tribunal de Contas da União para propor a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros.

Está correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

14. (Técnico de Controle Externo/TCU — CESPE/UnB/2012) A respeito do papel constitucional do TCU, julgue o item subsequente:

As empresas públicas federais não estão sujeitas à fiscalização do TCU, pois são pessoas jurídicas de direito privado.

15. (Analista Judiciário — TRE/CE — Área Administrativa — FCC/2012) Considerando que Anastácio, Santiago, Eric, Roberto e Pompeu ocupam respectivamente os cargos de Senador, Advogado, Defensor Público, Juiz de Tribunal Regional Federal e Prefeito Municipal, é certo que Péricles na qualidade de auditor do Tribunal de Contas da União, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as do cargo de:

- a) Anastácio.
- b) Santiago.
- c) Eric.
- d) Pompeu.
- e) Roberto.

■ 9.16.3. Processo legislativo

1. (Magistratura/172.º) Se o Presidente da República vetar projeto de lei cuja votação foi concluída na Câmara dos Deputados, o veto:

- a) será apreciado pela Casa em que a votação do projeto teve início, no prazo de quinze

dias contados do seu recebimento;

- b) será apreciado em sessão da Casa onde a votação foi concluída, no prazo de quinze dias contados do seu recebimento;
- c) será apreciado pelo Senado Federal, no prazo de trinta dias contados do seu recebimento;
- d) será apreciado em sessão conjunta das duas Casas do Congresso Nacional, no prazo de trinta dias contados do seu recebimento.

2. (Magistratura MG — 2004-2005) A iniciativa popular aplica-se a:

- a) proposta de emenda à Constituição.
- b) projeto de lei de iniciativa reservada.
- c) projeto de lei complementar.
- d) projeto de resolução.
- e) projeto de decreto legislativo.

3. (Magistratura MG — 2003 — prova escrita) A iniciativa popular aplica-se às propostas de emenda à Constituição?

4. (OAB/113.º) Trabalhadores de um ente estatal em fase de privatização, pretendendo emendar a Constituição Federal para proibir a alienação daquele ente, e não contando com o interesse do Presidente da República, nem do Senado Federal para a iniciativa da proposta de Emenda, devem conseguir, para tal objetivo, o apoio de, no mínimo, um terço:

- a) dos membros da Câmara dos Deputados;
- b) das Assembleias Legislativas dos Estados-membros;
- c) das Câmaras Municipais de um Estado-membro;
- d) do Congresso Nacional.

5. (OAB/118.º) Quanto à iniciativa de projeto de lei do Superior Tribunal de Justiça, pode-se afirmar que:

- a) terá início na primeira sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal, para aprovação em única votação;
- b) terá início no Senado Federal;
- c) terá início na Câmara dos Deputados;

d) o STJ não tem competência para iniciativa de lei.

6. (DP/RO/2007 — FJPF) Lei complementar que trate de normas gerais para a organização da Defensoria Pública do Estado é da iniciativa privativa do seguinte órgão:

- a) Senado Federal;
- b) Governo do Estado;
- c) Congresso Nacional;
- d) Assembleia Legislativa;
- e) Presidência da República.

7. (Magistratura — RR/FCC/2008) Projeto de lei ordinária de iniciativa do Presidente da República, visando à criação de cargos e empregos públicos na administração direta e autárquica federal, tramita em regime de urgência, em atendimento à solicitação do próprio Chefe do Poder Executivo federal. Nessa hipótese:

- a) o projeto de lei não deveria submeter-se a procedimento de urgência, pois a Constituição impede que o Presidente da República a solicite em proposições de sua iniciativa.
- b) terão as Casas do Congresso Nacional o prazo de quarenta e cinco dias, cada qual, para se manifestar sobre a proposição, sob pena de sobrestamento das demais deliberações legislativas da Casa respectiva, exceto as que tenham prazo constitucional determinado, até o fim da votação.
- c) padece o projeto de lei de vício de iniciativa, uma vez que não dispõe o Presidente da República de legitimidade para a apresentação de proposições que visem à criação de cargos e empregos públicos na administração autárquica federal.
- d) a matéria sobre a qual versa a proposição legislativa é reservada à lei complementar, sendo por essa razão o projeto de lei incompatível com a Constituição da República.
- e) a discussão e votação do projeto de lei terão início no Senado Federal, por se tratar de proposição legislativa de iniciativa privativa do Presidente da República.

8. (OAB CESPE/UnB-2008) No que diz respeito à disciplina constitucional relativa ao processo legislativo, assinale a opção correta:

- a) É da iniciativa reservada do STJ a lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura.
- b) O presidente da República dispõe de 48 horas para vetar um projeto de lei, contadas da data de seu recebimento, devendo, dentro de 24 horas, comunicar os motivos do veto

ao presidente do Senado Federal.

- c) A delegação legislativa é instituto de índole excepcional, devendo ser solicitada pelo presidente da República ao Congresso Nacional.
- d) O presidente da República poderá solicitar urgência para votação de projetos de lei da iniciativa tanto de deputados federais quanto de senadores.

9. (Defensoria Pública de São Paulo — FCC/2009) Em relação às cláusulas pétreas, considere as seguintes afirmações:

- I. Tem como significado último prevenir a erosão da Constituição Federal, inibindo a tentativa de abolir o projeto constitucional deixado pelo constituinte.
- II. A Emenda Constitucional 45, na parte que criou o Conselho Nacional de Justiça, violou, segundo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a cláusula pétrea da separação dos poderes.
- III. Ao petrificar o voto cristalizou-se a impossibilidade do poder constituinte derivado excluir o voto do analfabeto ou do menor entre 16 e 18 anos.
- IV. É possível que uma reforma constitucional crie novas cláusulas pétreas segundo entendimento pacífico da doutrina constitucional.
- V. A mera alteração redacional de uma norma originária componente do rol de cláusulas pétreas não importa em inconstitucionalidade.

Estão corretas SOMENTE:

- a) II, III e IV.
- b) III, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) I, III e V.
- e) I, IV e V.

10. (AGU — CESPE/UnB-2010) No que se refere ao processo legislativo, julgue o item subsequente:

Nos projetos orçamentários de iniciativa exclusiva do Presidente da República são admitidas, em caráter excepcional, emendas parlamentares que impliquem aumento de despesas.

11. (Analista Processual MPU — CESPE/UnB-2010) A administração pública, regulamentada no texto constitucional, possui princípios e características que lhe

conferem organização e funcionamento peculiares. A respeito desse assunto, julgue o próximo item:

Como decorrência do princípio da simetria e do princípio da separação dos poderes, as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da República, previstas na Constituição Federal, não podem ser estendidas aos governadores.

12. (XXXII MP/RJ — 2011) Quanto à proposta de emenda constitucional, é INCORRETO afirmar que:

- a) será efetuada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
- b) quando a matéria nela constante é rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
- c) não poderá ocorrer na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio;
- d) não será objeto de deliberação aquela tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.
- e) será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros e será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

13. (Analista Judiciário — TJ/ES — Direito — Área Judiciária — CESPE/UnB/2011) A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, estabelecia limitações de natureza temporal que não permitiram a reforma do texto constitucional durante certo intervalo de tempo.

14. (Analista Judiciário — Área Judiciária — TRT1/CESPE/UnB/2008) Em relação ao Poder Legislativo, assinale a opção correta:

- a) O Senado Federal poderá conceder eficácia *erga omnes* à decisão do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade.
- b) A decretação de estado de sítio, por motivos de segurança nacional, implica a automática suspensão da imunidade parlamentar.

- c) Em caso de guerra, a Câmara dos Deputados não pode recusar a convocação de parlamentar para as forças armadas.
- d) A Câmara dos Deputados tem competência para iniciativa de lei que vise à fixação da remuneração de seus servidores, mas a matéria deve ir à sanção do presidente da República.
- e) Compete ao Congresso Nacional a aprovação, com o *quorum* mínimo da maioria absoluta, do procurador-geral do Trabalho, pelo voto secreto, após arguição pública.

15. (Câmara dos Deputados — Analista Legislativo — CESPE/UnB/2012) Julgue o item seguinte, acerca do processo legislativo:

A CF determina que a votação de medidas provisórias se inicie na Câmara dos Deputados, cabendo à comissão mista de deputados e senadores examiná-las e sobre elas emitir parecer, antes que sejam apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional.

16. (Câmara dos Deputados — Analista Legislativo — CESPE/UnB/2012) Julgue o item subsecutivo, relativo a proposições:

A incorreção de técnica legislativa pode ser sanada por emenda de redação, cuja natureza é modificativa.

■ 9.16.4. Espécies normativas

1. (OAB/112.º) Poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição que suprima:

- a) o poder de veto do Presidente da República no processo legislativo;
- b) a justiça desportiva;
- c) o direito de impenhorabilidade da pequena propriedade rural;
- d) as competências legislativas do Distrito Federal.

2. (OAB/113.º) O ordenamento jurídico brasileiro permite a promulgação de Emenda Constitucional para tornar facultativo o voto para todos os cidadãos brasileiros e, posteriormente, a edição de Medida Provisória para regulamentar o artigo da Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional?

- a) não, pois a Emenda Constitucional estará abolindo cláusula pétrea;

- b) sim, pode ser promulgada a Emenda Constitucional, mas o artigo em questão não poderá ser regulamentado por Medida Provisória;
- c) sim, tanto a Emenda Constitucional como a Medida Provisória têm amparo constitucional;
- d) em termos, porque basta a Medida Provisória para tornar facultativo o voto.

3. (OAB/112.º) Sobre a lei complementar e a lei ordinária, vale dizer que são:

- a) distintas as matérias reservadas a cada uma delas, embora o *quorum* necessário para votação de ambas seja o mesmo;
- b) distintos os legitimados para apresentação dos respectivos projetos de lei;
- c) idênticos o *quorum* necessário para votação e as matérias reservadas a cada uma delas;
- d) distintas as matérias reservadas a cada uma delas, embora o *quorum* necessário para aprovação de ambas seja o mesmo.

4. (Magistratura/168.º) O Presidente da República poderá adotar medidas provisórias em caso de:

- a) calamidade pública;
- b) ameaça grave à ordem pública ou à paz social;
- c) violação de direitos humanos;
- d) relevância e urgência.

5. (Procurador do Estado MA/2003) Medida Provisória editada anteriormente à EC n. 32/2001 e ainda em vigência na data da promulgação dessa emenda, que modificou a disciplina da matéria na Constituição Brasileira de 1988:

- a) é considerada automaticamente aprovada, convertendo-se em lei pela sanção do Presidente da República;
- b) perde totalmente sua eficácia desde a edição da EC n. 32/2001, independentemente da matéria nela versada;
- c) continua em vigor até que medida provisória ulterior a revogue expressamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional sobre a mesma;
- d) tem apenas resguardados os efeitos produzidos constantes de decisão transitada em julgado;
- e) tem expressamente resguardados apenas os direitos adquiridos dela decorrentes.

6. (OAB/118.º) Em fevereiro de 2002, determinada matéria sobre meio ambiente é disciplinada em projeto de lei que é aprovado pelo Congresso Nacional, mas que

aguarda a sanção ou o veto do Chefe do Executivo. Mesmo ciente de tal pendência, o Presidente da República, com base na relevância e urgência, expede Medida Provisória dispondo sobre a mesma matéria constante do referido projeto de lei. Em face das recentes alterações constitucionais, a Medida Provisória em questão deverá ser considerada:

- a) constitucional, pois atende a todos os requisitos previstos na Constituição Federal;
- b) inconstitucional, pois é vedada a adoção de Medida Provisória sobre matéria ambiental;
- c) inconstitucional, pois a “relevância” e a “urgência” não são mais pressupostos para adoção de Medida Provisória;
- d) inconstitucional, pois é vedada a adoção de Medida Provisória que verse sobre matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

7. (OAB/118.º) A medida provisória que verse sobre telecomunicações e que tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional:

- a) nunca poderá ser reeditada;
- b) poderá ser reeditada na legislatura subsequente;
- c) poderá ser reeditada na sessão legislativa subsequente;
- d) poderá ser prorrogada pelo prazo máximo de 60 dias.

8. (MP/SE/02) Considere a hipótese de Resolução do Congresso Nacional delegar ao Presidente da República a elaboração de uma lei, especificando seu conteúdo, os termos de seu exercício e determinando a apreciação do projeto pelo Poder Legislativo. Nesse caso, o Congresso Nacional deliberará em:

- a) duas votações, em cada uma das Casas, sendo permitidas emendas supressivas e aditivas;
- b) duas votações das Casas reunidas, sendo vedada qualquer emenda;
- c) duas votações das Casas reunidas, sendo permitidas somente as emendas supressivas;
- d) votação única, sendo permitidas somente as emendas supressivas;
- e) votação única, sendo vedada qualquer emenda.

9. (TJ/SC 2007) A respeito do processo de criação da MEDIDA PROVISÓRIA é correto afirmar:

- a) A Emenda Constitucional n. 32, de 11/09/2001, modificou radicalmente o processo de

tramitação da medida provisória para sua conversão em lei, impedindo, inclusive, sua prorrogação.

- b) A regulamentação estabelecida na Emenda Constitucional n. 32/2001 se dirige àquelas medidas provisórias editadas antes e após sua promulgação.
- c) A medida provisória tem a particularidade de nascer como diploma normativo pela tão só manifestação do Chefe do Executivo. A discussão é posterior. A aprovação converte a medida provisória em lei.
- d) Se o projeto de lei de conversão da medida provisória alterar o seu texto, suspender-se-á imediatamente sua vigência.
- e) A votação da medida provisória dar-se-á de forma conjunta pelas Casas do Congresso Nacional.

10. (Delegado de Polícia/AC/CESPE/UnB-2008) Considere que seja editada uma lei federal determinando que são penalmente imputáveis os maiores de 16 anos. Essa lei seria incompatível com a Constituição Federal.

11. (Magistratura — TJ/SC 2009) Assinale a alternativa INCORRETA no tocante ao instituto da medida provisória:

- a) Dentre outras hipóteses, é defeso editá-la sobre matéria já disciplinada em projeto de lei pendente de sanção ou veto.
- b) Cumpre ao Poder Legislativo disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes de sua não conversão em lei.
- c) É vedada sua reedição, na mesma legislatura, se rejeitada ou tornada ineficaz por decurso de prazo.
- d) Urgência e relevância são pressupostos para sua adoção.
- e) Perderá sua eficácia se não convertida em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, uma vez, por igual período.

12. (87.º/MP/SP 2010) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos (3/5) dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes:

- a) às emendas constitucionais.
- b) às leis complementares.
- c) às leis ordinárias.

- d) às leis delegadas.
- e) aos decretos legislativos.

13. (Advogado/AGU — CESPE/UnB/2012) Julgue o item a seguir, acerca da ordem econômica e financeira e da edição de medida provisória sobre matéria tributária:

A CF admite a edição de medida provisória que institua ou majore impostos, desde que seja respeitado o princípio da anterioridade tributária.

14. (Inspetor de Polícia Civil/CE — CESPE/UnB/2012) Julgue o item que se segue, acerca do direito constitucional, considerando a Constituição da República de 1988 (CF):

Em função do sistema de distribuição de competências legislativas criado pela CF, há nítida superioridade hierárquica das leis federais sobre as estaduais.

15. (Magistratura/CE — CESPE/UnB/2012) Acerca do processo legislativo na ordem jurídica pátria, assinale a opção correta:

- a) Celebrado tratado, convenção ou ato internacional pelo presidente da República, cabe ao Congresso Nacional o correspondente referendo ou aprovação, mediante a edição de resolução específica.
- b) No processo legislativo da lei ordinária, o veto presidencial parcial pode abranger trecho, palavras ou expressões constantes de artigo, parágrafo ou alínea.
- c) O controle exercido pelo Congresso Nacional sobre a lei delegada opera efeitos *ex tunc*.
- d) Segundo o STF, uma vez editada a medida provisória, não pode o Presidente da República retirá-la da apreciação do Congresso Nacional nem tampouco ab-rojá-la por meio de nova medida provisória.
- e) Lei ordinária posterior pode revogar lei formalmente complementar, desde que materialmente ordinária.

16. (Defensor Público/AM — FCC/2013) De acordo com a jurisprudência atualmente predominante no Supremo Tribunal Federal, um tratado internacional de direitos humanos, ratificado na forma do artigo 5.º, parágrafo 2.º, da Constituição Federal, possui força normativa equivalente à de norma:

- a) formalmente constitucional.
- b) legal ordinária.
- c) legal complementar.

d) supralegal e infraconstitucional.

e) regulamentar.

■ GABARITO ■

■ 9.16.1. Do Poder Legislativo — Aspectos gerais (estrutura, atribuições, reuniões, comissões, imunidades, incompatibilidades e impedimentos, perda do mandato)

1. “b”. Art. 27, *caput*. O bicameralismo federativo é característica do Poder Legislativo Federal (duas Casas — Câmara dos Deputados e Senado Federal). O Legislativo estadual, distrital e municipal é unicameral.

2. “c”. Art. 58, § 3.º.

3. “b”. Art. 58, § 3.º Analisemos as outras alternativas: a letra “a” está errada, já que a única hipótese de prisão a ser decretada pela CPI é a em flagrante delito; a letra “c”, muito embora traga uma afirmação correta, qual seja, ter a CPI o poder de decretar a quebra de sigilo bancário, o erro está em dizer que os seus poderes serão os mesmos da autoridade policial, pois, como vimos, os poderes de investigação são próprios da autoridade judicial; o erro da letra “d” está em dizer que a CPI promoverá a responsabilização. Como estudamos, a CPI investiga. Suas conclusões serão encaminhadas ao MP para que este promova a responsabilização civil ou criminal dos infratores.

4. “a”. Conforme vimos na parte teórica, há que se observar a simetria do modelo federal, previsto no art. 58, § 3.º, da CF/88.

5. “b”.

6. “a”. Cf. parte teórica.

7. “errado”.

8. “d”. Regra trazida pela EC n. 35/2001, nos termos do art. 53, § 3.º.

9. “c”. Art. 27, *caput*, nos seguintes termos: “o número de Deputados à Assembleia Legislativa

corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze”. Conforme vimos na parte teórica, para Estados com representação na CD acima de 12 membros, a fórmula será a seguinte: $y = (x - 12) + 36$, em que y = número de Deputados Estaduais e x = número de Deputados Federais. A fórmula, para facilitar, pode ser assim resumida: $y = x + 24$, em que y = número de Deputados Estaduais e x = número de Deputados Federais (quando forem acima de 12).
10. “errado”, já que a resposta seria 75 deputados estaduais, nos termos do art. 27, <i>caput</i>, da CF/88. Cf. <i>item 9.1.2.1</i>.
11. “b”.
12. “b”, de acordo com o art. 53, § 2.º. Assim, esse é o motivo do erro da letra “a”. A letra “c” está errada, já que uma das novidades da EC n. 35/2001 foi a possibilidade de instauração do processo, independentemente de autorização da Casa legislativa (cf. art. 53, § 3.º). A letra “d” está errada, na medida em que os parlamentares federais têm por prerrogativa de foro o STF, e não o STJ (art. 53, § 1.º).
13. “c”, cf. art. 29, VI. A letra “a” está errada porque viola o art. 29, V, já que a lei é de iniciativa da Câmara Municipal. Em igual sentido, a letra “b” está errada por violar o art. 29, V. A letra “d”, por sua vez, está errada por violar o art. 29, VI.
14. “c”, conforme o art. 57, § 3.º, IV. A letra “a” está errada, pois houve a conceituação de sessão legislativa ordinária, prevista no art. 57. A letra “b” está errada, pois conceituou legislatura (vejam que eles inverteram os conceitos nas letras “a” e “b”). A letra “d” está errada, pois a regra de convocação extraordinária prevista no art. 57, § 6.º, II, é na hipótese de urgência ou interesse público relevante, sem que se restrinja a uma única exceção, como afirma a alternativa.
15. “certo”, de acordo com o art. 49, XVI. Assim, como temos dito, estudem a “letra de lei”!
16. “certo”, de acordo com o art. 46, §§ 1.º e 3.º.
17. “b”, de acordo com o art. 49, XII.
■ 9.16.2. Tribunal de Contas

1. “a”. Art. 31.
2. “c”. De acordo com o art. 74, § 2.º, da CF, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Em âmbito federal, o procedimento é regulamentado pela Lei n. 8.443/92
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). De acordo com o art. 53, § 3.º, da referida lei, a denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do responsável. Como garantia e incentivo da denúncia popular, o art. 55, § 2.º, da lei estabeleceu que o denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé.
3. “d”. Cuidado! Muitos erraram essa questão, respondendo como certa a letra “b”. Como enfatizamos na parte teórica, as contas do Presidente da República (controle externo) são julgadas pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU! Cf. arts. 70 e 71, I e II, da CF/88 (o inciso I fala em “apreciar”, e o inciso II, em “julgar”).
4. “d”. José Afonso da Silva, ao comentar o art. 71, II, destacou: “... não se trata de função jurisdicional, pois não julga pessoas nem dirime conflitos de interesses, mas apenas exerce um julgamento técnico de contas” (<i>Curso de direito constitucional positivo</i> , 20. ed., p. 731).
5. “a”. Arts. 70, parágrafo único, e 71, II e VIII, da CF; arts. 57 e s. da Lei n. 8.443/92; STF, <i>RTJ</i> 160/448 e a jurisprudência do TCU (julgados disponíveis em: < http://www.tcu.gov.br >).
6. “a”. Art. 71, § 3.º, da CF/88.
7. “b”.
8. “c”.
9. “c”. Art. 70, <i>caput</i> , da CF/88.
10. “e”. Art. 71, incisos e §§ 1.º e 2.º.
11. “e”. Art. 71, § 3.º.
12. “a”. Art. 73, § 3.º.

13. “e”. Item I, cf. art. 73, § 3.º, c/c o art. 75, <i>caput</i> . Item II, cf. art. 31, § 2.º. Item III, cf. art. 73, <i>caput</i> , c/c o art. 96, II, “b”, da CF/88.
14. “errado”, cf. parte teórica.
15. “e”. Além de muita atenção, essa questão exigia o conhecimento da literalidade do art. 73, § 4.º.
■ 9.16.3. Processo legislativo
1. “d”. Art. 66, § 4.º.
2. “c”. Art. 61, § 2.º, da CF/88, apenas lembrando a discussão e remetendo o leitor para a parte teórica, no tocante à PEC e aos projetos de iniciativa reservada do Presidente da República previstos no art. 61, § 1.º. A pergunta poderia ter sido mais bem formulada, nos seguintes termos, com todo o respeito: “A iniciativa popular, expressamente prevista na CF/1988, aplica-se a:”.
3. <i>vide</i> parte teórica, <i>item 9.13.3.4.4</i> .
4. “a”. Trata-se de um dos legitimados concorrentes (iniciativa concorrente) para deflagrar o processo legislativo de emendas à Constituição (art. 60, I, da CF). Só para fixar, é importante que saibam, para as provas, os outros legitimados: a) 1/3, no mínimo, dos membros do SF (art. 60, I); b) o Presidente da República (art. 60, II); c) mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros (art. 60, III).
5. “c”. Art. 64, <i>caput</i> , da CF/88. A Câmara dos Deputados é, portanto, a Casa iniciadora e o Senado Federal, a Casa revisora, respeitando, dessa forma, o princípio do bicameralismo federativo.
6. “e”. Art. 61, § 1.º, II, “d”.
7. “b”. Art. 64, § 2.º, da CF/88. Lembrar a discussão no MS 27.931, no qual o Presidente da Câmara entendeu que não ficariam trancadas as matérias que, em tese, não poderiam ser objeto de MP, como, por exemplo, PEC (matéria pendente de julgamento pelo STF).
8. “c”.
9. “b”.

10. “certo”. Art. 63, I, c/c o art. 166, §§ 3.º e 4.º.
11. “errado”. Conforme visto na parte teórica, as hipóteses de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo federal devem, necessariamente, ser estendidas aos demais Chefes dos Executivos, no seu âmbito.
12. “b”. Letra “a”, cf. art. 60, I (legitimados para o encaminhamento de PEC: decorem!). A letra “b” está errada porque, nos termos do art. 60, § 5.º, a vedação é para o encaminhamento de nova proposta na mesma sessão legislativa (definida no art. 57), e não legislatura, que é o período de 4 anos e que corresponde ao mandato de um Deputado Federal (realmente, <i>pegadinha</i> !). A letra “c” encontra fundamento no art. 60, § 1.º. A letra “d” exige o conhecimento das denominadas cláusulas pétreas (art. 60, § 4.º, I a IV: memorizem!). Finalmente, a letra “e” repete a literalidade do art. 60, §§ 2.º e 3.º.
13. “errado”.
14. “d”. Cf. art. 51, IV.
15. “certo”, art. 62, § 9.º.
16. “certo”, de acordo com a parte teórica.
■ 9.16.4. Espécies normativas
1. “b”. Art. 60, § 4.º, cláusulas pétreas. A supressão da justiça desportiva não fere nenhuma das cláusulas pétreas. A supressão do poder de veto do Presidente da República afrontaria a separação dos Poderes (art. 60, § 4.º, III). O direito de impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito e garantia individual (art. 60, § 4.º, IV). Por fim, a alternativa “d”, caso aprovada por emenda, feriria a cláusula pétrea da forma federativa de Estado (art. 60, § 4.º, I).
2. “b”. Art. 60, § 4.º, c/c o art. 246 da CF. Essa questão muita gente errou! Tomem cuidado! Ser facultativo ou obrigatório o voto no Brasil não é cláusula pétrea. O que não poderá ser alterado por emenda, nos termos do art. 60, § 4.º, II, é o voto direto, secreto universal e periódico, nada tendo sido dito sobre a sua obrigatoriedade ou não. O candidato deveria ter-se lembrado, também, do art. 246 da CF, que veda a adoção de MP na regulamentação de artigo da CF cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1.º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de

2001, data da promulgação da EC n. 32/2001, (cf. a nova redação dada ao referido art. 246 pela aludida emenda constitucional).
3. “a”. Art. 47 c/c os arts. 69 e 61, cf. exaustivamente visto na parte teórica. O <i>quorum</i> de votação (e aí melhor seria <i>quorum</i> de instalação da sessão de votação) é o mesmo, qual seja, o da maioria absoluta. O <i>quorum</i> de aprovação é distinto: a) lei ordinária: maioria simples; b) lei complementar: maioria absoluta. As matérias reservadas à LC estão taxativamente previstas na CF, enquanto as de lei ordinária ocupam um campo material residual.
4. “d”. Art. 62.
5. “c”, de acordo com o art. 2.º da EC n. 32/2001.
6. “d”. Regra trazida pela EC n. 32/2001, nos termos do art. 62, IV.
7. “c”. Regra trazida pela EC n. 32/2001. Conforme vimos, o art. 62, § 10, dispõe ser vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Logo, <i>a contrario sensu</i> , pela literalidade da EC n. 32/2001, na sessão legislativa seguinte seria permitida a reedição da MP, inclusive se expressamente rejeitada. Não confundir sessão legislativa (reunião anual, em Brasília, do Congresso Nacional, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro, nos termos do art. 57, <i>caput</i> , na redação dada pela EC n. 50/2006) com legislatura (período de 4 anos que corresponde ao mandato dos Deputados). Por fim, salvo melhor juízo, entendemos que a matéria da questão (telecomunicações) não poderia ser objeto de MP, nos termos do art. 2.º da EC n. 8/95 . Assim, a aludida questão deveria ser anulada (quem tiver posicionamento em contrário, por favor, fique à vontade para enviar um <i>e-mail</i> para discussão!). Esse mesmo problema aconteceu no exame 119.º em relação à legislação que regulamenta a interceptação das comunicações telefônicas.
8. “e”. Art. 68, § 3.º, da CF/88. Lembrar que essa hipótese de apreciação pelo Congresso Nacional é facultativa, e que poderia ter sido dispensada na Resolução que delegou a atribuição para o Presidente da República elaborar a lei delegada.
9. “c”.
10. “certo”.

11. “c”. Nos termos do art. 62, § 10, é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato de um Deputado. Sessão legislativa está definida no art. 57.
12. “a”. Art. 5.º, § 3.º.
13. “certo”, de acordo com o art. 62, § 2.º.
14. “errado”.
15. “e”.
16. “d”.

PODER EXECUTIVO

■ 10.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Exercendo funções típicas, o órgão executivo, como já visto, pratica atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. **Atipicamente**, o Executivo *legisla*, por exemplo, via medida provisória (art. 62) e *julga*, no “contencioso administrativo”, exercido em caso de defesa de multa de trânsito, do IPEM, da SEMAB, TIT etc.

O sistema de governo adotado pela CF/88, mantido pelo plebiscito previsto no art. 2.º do ADCT, é o **presidencialista**, influenciado, historicamente, pela experiência norte-americana. Trata-se, inclusive, de tradição do direito constitucional pátrio, vivenciada durante toda a República, com exceção do período de 1961 a 1963. Como se recorda, a Emenda Constitucional n. 4, de 02.09.1961, à Constituição de 1946, instituiu o **parlamentarismo**, sendo revogada pela Emenda n. 6, de 23.01.1963, restauradora do regime presidencialista, tendo em vista o resultado do **referendo** realizado em 6 de janeiro de 1963, que decidiu pelo retorno ao presidencialismo.

■ 10.2. PRESIDENCIALISMO *VERSUS* PARLAMENTARISMO

No sistema **presidencialista**, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, o **Presidente da República**. Já no **parlamentarismo**, a função de Chefe de Estado é exercida

pelo **Presidente da República** (República parlamentarista) ou **Monarca** (Monarquia parlamentarista), enquanto a função de Chefe de Governo, pelo **Primeiro-Ministro**, chefiando o Gabinete. Vejamos algumas outras características:

■ **presidencialismo**: criação norte-americana; eleição do Presidente da República pelo povo, para mandato determinado; ampla liberdade para escolher os Ministros de Estado, que o auxiliam e podem ser demitidos *ad nutum*, a qualquer tempo;

■ **parlamentarismo**: produto de longa evolução histórica; adquiriu os contornos atuais no final do século XIX, recebendo forte influência inglesa; o Primeiro-Ministro, que é quem exerce, de fato, a função de Chefe de Governo, é apontado pelo Chefe de Estado, só se tornando Primeiro-Ministro com a **aprovação do Parlamento**; o Primeiro-Ministro, também, não exerce mandato por prazo determinado, pois poderá ocorrer a queda de governo por dois motivos, a saber: se **perder a maioria parlamentar** pelo partido a que pertence, ou através do **voto de desconfiança**; possibilidade de dissolução do Parlamento, declarando-se extintos os mandatos pelo Chefe de Estado e convocando-se novas eleições.

CONCLUSÃO: no presidencialismo fica mais bem caracterizada a separação de funções estatais. Isso porque, diz Michel Temer, “no parlamentarismo verifica-se o deslocamento de uma parcela da atividade executiva para o Legislativo. Nesse particular fortalece-se a figura do *Parlamento* que, além da atribuição de inovar a ordem jurídica em nível imediatamente infraconstitucional, passa a desempenhar, também, função executiva”.¹

Nesse mesmo sentido, José Afonso da Silva, identificando uma nova visão da teoria da separação dos poderes, bem como novas formas de relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo e destes com o judiciário, “... prefere falar em *colaboração de poderes*, que é característica do parlamentarismo, em que o governo depende da confiança do Parlamento (Câmara dos Deputados), enquanto, no presidencialismo, desenvolveram-se as técnicas da *independência orgânica e harmonia dos poderes*”.²

■ 10.3. EXECUTIVO MONOCRÁTICO, COLEGIAL, DIRETORIAL E DUAL — CONCEITO

Como anota José Afonso da Silva, “Maurice Duverger mostra que o Executivo reveste na prática formas as mais diversas, encontrando-se *executivo monocrático* (Rei, Imperador, Ditador, Presidente), *executivo colegial* (para ele, é o exercido por dois homens com poderes iguais, como os cônsules romanos), *executivo diretorial* (grupo de homens em *comitê*, como era na Ex-URSS e ainda é na Suíça) e *executivo dual* (próprio do parlamentarismo, um Chefe de Estado e um Conselho de Ministros, ou seja, um indivíduo isolado e um *comitê*)”.[3](#)

Podemos afirmar, então, que o art. 76 da CF/88 consagra a figura, segundo Duverger, de um **executivo monocrático**, na medida em que as funções de Chefe de Estado e de Governo são exercidas por um só indivíduo, no caso o Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

■ 10.4. O PODER EXECUTIVO NA CF/88

■ 10.4.1. O exercício do Poder Executivo no Brasil

■ 10.4.1.1. *Âmbito federal*

O Poder Executivo no Brasil, estabelece o art. 76, é exercido pelo **Presidente da República**, auxiliado pelos Ministros de Estado.

Como visto, há um acúmulo do exercício das funções de Chefe de Estado e de Governo na figura de uma única pessoa, no caso, o Presidente da República. As regras serão detalhadas individualmente. Antes, porém, teceremos alguns comentários sobre o executivo estadual, distrital, municipal e dos Territórios Federais.

■ 10.4.1.2. Âmbito estadual

Em **âmbito estadual**, o Poder Executivo é exercido pelo Governador de Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado, sendo substituído (no caso de impedimento) ou sucedido (no caso de vaga), pelo Vice-Governador, com ele eleito, observando-se algumas outras regras:

■ **eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado:** será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1.º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 (art. 28, *caput*);

■ **mandato:** o mandato é de 4 anos, permitindo-se a reeleição para um único período subsequente (art. 28, *caput*, c/c o art. 14, § 5.º);

■ **perda do mandato:** perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V (art. 28, § 1.º);

■ **subsídios do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado:** o subsídio do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI; 39, § 4.º; 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I (art. 28, § 2.º, acrescentado pela EC n. 19/98).

■ 10.4.1.3. Âmbito distrital

■ **eleição:** o art. 32, § 2.º, dispõe que a eleição do Governador e do Vice-Governador do DF, observadas as regras do art. 77, coincidirá com a dos Governadores Estaduais;

■ **mandato:** 4 anos, permitindo-se a reeleição para um único período subsequente (art. 32, § 2.º, c/c o art. 14, § 5.º).

■ 10.4.1.4. *Âmbito municipal*

O art. 29, I a III, fixa as seguintes regras sobre o Poder Executivo municipal:

■ **eleição:** do Prefeito, do vice-Prefeito, para mandato de **4** anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com mais de **200** mil eleitores, sendo permitida a reeleição para um único período subsequente (art. 14, § 5.º);

■ **posse:** do Prefeito e do Vice-Prefeito em 1.º de janeiro do ano subsequente ao da eleição;

■ **perda do mandato:** perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V (art. 28, § 1.º — primitivo parágrafo único, transformado em § 1.º pela EC n. 19/98, c/c o art. 29, XIV, inciso renumerado pela EC n. 1/92).

■ 10.4.1.5. *Âmbito dos Territórios Federais*

A direção dos Territórios Federais dar-se-á por Governador, **nomeado** pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal (cf. arts. 33, § 3.º; 52, III, “c”; e 84, XIV).

■ 10.4.2. *Atribuições conferidas ao Presidente da República*

■ 10.4.2.1. *Regras gerais do art. 84 da CF/88*

O art. 84 atribui ao Presidente da República competências privativas, tanto de natureza de **Chefe de estado** (representando a República Federativa do Brasil nas relações internacionais e, internamente, sua unidade, previstas nos incisos VII, VIII e XIX⁴ do art. 84) como de **Chefe de Governo** (prática de atos de

administração e de natureza política — estes últimos quando participa do processo legislativo — conforme se percebe pela leitura das atribuições previstas nos incisos I a VI; IX a XVIII e XX a XXVII).

Em razão da *incidência nos concursos*, sugerimos uma leitura atenta das atribuições previstas no art. 84 da CF/88, que, ao regular a matéria, dispõe ser competência privativa do Presidente da República:

- **I** — nomear e exonerar os Ministros de Estado;
- **II** — exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- **III** — iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição (cf. art. 61, § 1.º);
- **IV** — sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
- **V** — vetar projetos de lei, total ou parcialmente (cf. art. 66);
- **VI** — dispor, mediante decreto, sobre: **a)** organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**; **b)** extinção de funções ou cargos públicos, quando **vagos**;
- **VII** — manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
- **VIII** — celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a **referendo** do Congresso Nacional (cf. art. 49, I);
- **IX** — decretar o estado de defesa e o estado de sítio (cf. arts. 136 a 141);
- **X** — decretar e executar a intervenção federal (cf. art. 34);
- **XI** — remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
- **XII** — conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

- **XIII** — exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos (cf. art. 142);
- **XIV** — nomear, **após aprovação pelo Senado Federal** (*sabatina*), os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei;
- **XV** — nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
- **XVI** — nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
- **XVII** — nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
- **XVIII** — convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
- **XIX** — declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
- **XX** — celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
- **XXI** — conferir condecorações e distinções honoríficas;
- **XXII** — permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente (cf. LC n. 90/97 com as alterações introduzidas pela LC n. 149/2015);
- **XXIII** — enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

- **XXIV** — prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
- **XXV** — prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
- **XXVI** — editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
- **XXVII** — exercer **outras atribuições** previstas nesta Constituição.

■ **10.4.2.2. Regras específicas decorrentes do art. 84 da CF/88**

Diante dessas informações, surgem duas indagações:

- **as atribuições conferidas ao Presidente da República estão taxativamente previstas no art. 84?**
- **poderiam elas ser delegadas?**

Respondendo à **primeira pergunta**, devemos dizer que o rol do art. 84 é meramente **exemplificativo**, pois, conforme o seu inciso XXVII, compete privativamente ao Presidente da República exercer não só as atribuições definidas nos incisos precedentes bem como **outras** previstas na CF/88.

No tocante à **segunda pergunta**, devemos respondê-la afirmativamente. No entanto, resta observar que o Presidente da República somente poderá delegar as atribuições previstas nos incisos **VI, XII e XXV, primeira parte**, aos **Ministros de Estado**, ao **Procurador-Geral da República** ou ao **Advogado-Geral da União**, devendo todos observar os limites traçados nas respectivas delegações (cf. art. 84, parágrafo único), quais sejam, as atribuições de:

- dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**;
- dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou de cargos públicos, quando **vagos**;

■ conceder **indulto** e **comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

■ **prover** os **cargos** públicos federais, na forma da lei.

Em relação a esta última atribuição, havendo delegação para prover cargos, a dúvida surge em saber se essa autorização abrangeria, também, a atribuição para **desprover** cargos, praticando-se atos demissionários de servidores públicos.

Por exemplo, indaga-se se seria possível determinado Ministro de Estado, por meio de portaria, havendo delegação nos termos do art. 84, parágrafo único, após procedimento administrativo, no qual se assegurou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena de demissão a servidor público?

Sim.

Conforme anotou o Min. Ayres Britto, “aqui se aplica a regra elementar de que quem tem competência para nomear também tem para ‘**desnomear**’, chamemos assim, apliquemos o neologismo” (voto no *RMS 24.619*, p. 58). Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do STF:

“EMENTA: 1. Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Presidente da República: competência para **prover** cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de **desprovê-los**, a qual, portanto, é **suscetível de delegação a Ministro de Estado** (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que — à luz do Decreto 3.035/99, cuja constitucionalidade se declara — demitiu o recorrente” (**MS 24.128**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07.04.2005, Plenário, *DJ* de 01.07.2005).⁵

Para se ter um exemplo sobre o tema em análise, destacamos o **Decreto n. 3.035/99** pelo qual o Presidente da República delegou competência para a prática dos atos que menciona aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União, e dá outras providências.

Finalmente, por simetria, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no **âmbito estadual**. Na medida em que a atribuição para demissão de servidor público

estadual é do Governador do Estado, o STF vem admitindo a delegação dessa atribuição para Secretário de Estado. Vejamos:

“EMENTA: I — Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de **delegação a Ministro de Estado** da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar **pena de demissão a servidores públicos federais**. II — **Legitimidade da delegação a secretários estaduais da competência do Governador do Estado de Goiás para (...) aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria**. Precedentes” (RE 633.009-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.09.2011, 2.^a T., DJE de 27.09.2011).

■ 10.4.2.3. O poder regulamentar e a realidade dos denominados “decretos autônomos”

Passamos agora, dada a importância, a comentar o **inciso IV** do art. 84, que atribui competência privativa ao Presidente da República para sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como **expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução**.

Trata-se do poder regulamentar, que se perfaz mediante **decretos regulamentares**. Como regra geral, o Presidente da República materializa as competências do art. 84 por **decretos**. É o instrumento através do qual se manifesta. No tocante às leis, algumas são autoexecutáveis. Outras precisam de regulamento para que seja dado fiel cumprimento aos seus preceitos. Para tanto, são expedidos os **decretos regulamentares**.

Neste ponto, devemos enfrentar questão tormentosa: poderiam existir **decretos autônomos**, independentes de lei preexistente?

Sabe-se que o conteúdo e a amplitude do regulamento devem sempre estar **definidos em lei**, subordinando-se aos preceitos nela previstos. Quando o regulamento extrapolar a lei, padecerá de vício de **legalidade**,⁶ podendo, inclusive, o Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V).

Isso porque, ao contrário da lei, fonte primária do direito, o regulamento se caracteriza como fonte secundária. Outro entendimento feriria o **princípio da legalidade** previsto no art. 5.º, II, da CF/88, bem como o **princípio da separação de Poderes**, previsto no art. 2.º e elevado à categoria de cláusula pétrea (art. 60, § 4.º, III), uma vez que a expedição de normas gerais e abstratas é **função típica do legislativo**. Quando o constituinte originário atribui função atípica de natureza legislativa ao Executivo, ele o faz de modo expresso, por exemplo, no art. 62 (medidas provisórias).

Apesar de grande parte da doutrina manifestar-se pela **inexistência** de acolhida constitucional dos **regulamentos autônomos**, o STF não desconhece essa realidade e admite, até mesmo, o controle por **ADI genérica**, na hipótese de **decreto autônomo** revestido de **indiscutível conteúdo normativo**.⁷

Entendemos que, a partir do advento da EC n. 32/2001, que modificou a redação dada ao art. 84, VI, da CF/88, passamos a ter exemplos factíveis de **decreto autônomo**. Nesse sentido:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. **Execução de lei inconstitucional**. Caráter residual de decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. **É admissível controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução à lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações. Inconstitucionalidade**. Ação direta. Art. 5.º da Lei 1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1.º, II, ‘a’, e 84, VI, ‘a’, da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução” (ADI 3.232,

Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.08.2008, Plenário, *DJE* de 03.10.2008). No mesmo sentido: ADI 3.983 e ADI 3.990. Cf. *Inf. 515/STF*.

■ 10.4.3. Condições de elegibilidade

As condições de elegibilidade definidas pela Constituição de 1988 para o cargo de Presidente e Vice-Presidente da República [8](#) são:

- ser brasileiro nato (art. 12, § 3.º, I);
- estar no pleno exercício dos direitos políticos (art. 14, § 3.º, II);
- alistamento eleitoral (art. 14, § 3.º, III);
- domicílio eleitoral na circunscrição (art. 14, § 3.º, IV);
- filiação partidária (arts. 14, § 3.º, V, e 77, § 2.º);
- idade mínima de 35 anos (art. 14, § 3.º, VI, “a”);
- não ser inalistável nem analfabeto (art. 14, § 4.º);
- não ser inelegível nos termos do art. 14, § 7.º.

■ 10.4.4. Processo eleitoral

As regras para a eleição do Presidente e Vice-Presidente da República estão previstas no art. 77 da CF/88.

Portanto, a data da eleição já está previamente fixada no art. 77, *caput*, na redação determinada pela EC n. 16/97, qual seja, no **primeiro domingo de outubro**, em primeiro turno, e no **último domingo de outubro**, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

Não haverá segundo turno se o candidato à Presidência da República (juntamente com o Vice-Presidente) for eleito em primeiro turno, o que se dá quando obtém a **maioria absoluta** de votos, não computados os em branco e os nulos.

Na hipótese de nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira

votação, far-se-á nova eleição no **último domingo de outubro** do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito, agora em segundo turno, aquele que obtiver a **maioria** dos votos válidos. [9](#)

Havendo necessidade de segundo turno, se antes de realizado ocorrer **morte, desistência** ou **impedimento legal de candidato**, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de **maior votação**. Nesta última hipótese, havendo **empate** em segundo lugar, ou seja, se dentre os remanescentes houver dois candidatos com a mesma votação, o desempate será empreendido levando-se em consideração a **idade**, sendo chamado o mais idoso (cf. art. 77, §§ 3.º e 4.º).

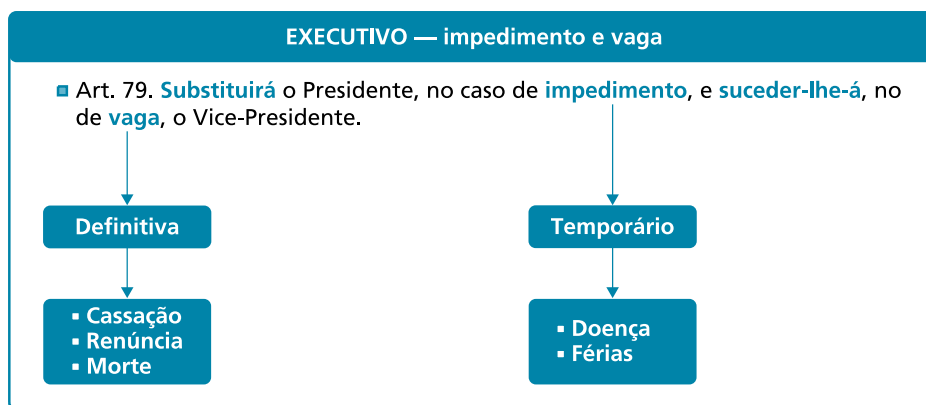
■ 10.4.5. Posse e mandato

Eleito o Presidente da República, juntamente com o Vice-Presidente (art. 77, § 1.º), [10](#) tomarão **posse** em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, [11](#) observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil (art. 78).

O **mandato** do Presidente da República é de **4 anos**, tendo início em **1.º de janeiro** do ano seguinte ao da sua eleição (art. 82), sendo atualmente, em decorrência da EC n. 16/97, **permitida a reeleição**, para um **único período subsequente**, do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, dos Prefeitos e de quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos (art. 14, § 5.º, na redação determinada pela EC n. 16/97). [12](#)

■ 10.4.6. Impedimento e vacância dos cargos

■ 10.4.6.1. *Sucessor e substituto natural do Presidente da República: Vice-Presidente*



O Presidente da República será **sucedido** pelo Vice-Presidente no caso de **vaga**, ou **substituído**, no caso de **impedimento** (art. 79). A **vacância** nos dá uma ideia de impossibilidade **definitiva** para assunção do cargo (cassação, renúncia ou morte), enquanto a **substituição** tem **caráter temporário** (por exemplo: doença, férias etc.). Assim, tanto na vacância como no impedimento, o Vice-Presidente assumirá o cargo, na primeira hipótese, até final do mandato e, no caso de impedimento, enquanto este durar.

Podemos afirmar, então, que o **Vice-Presidente da República** aparece como o **sucessor** e o **substituto natural** do Presidente da República e, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por **lei complementar**, auxiliará o Presidente, sempre que for por ele convocado para missões especiais.

Na história constitucional do Brasil lembramos, dentre tantos exemplos, a **sucessão** (definitiva) do cargo de Presidente da República pelo então Vice-Presidente **José Sarney**, em 15.03.1985, em razão da morte de Tancredo Neves, tendo sido o primeiro Governo Civil após o movimento militar de 1964.

Destacamos, também, a sucessão por **Itamar Franco**, em 02.10.1992, empossado em razão da vacância do cargo de Fernando Collor, que, formalmente, renunciou, após a autorização da abertura do processo de *impeachment*, pela Câmara dos Deputados.

■ 10.4.6.2. *Substitutos eventuais ou legais*

Pode haver um **impedimento** temporário tanto do Presidente como do Vice-Presidente da República, quando, por exemplo, ausentarem-se do País.

Ainda, é possível pensar em vaga dos cargos. Imaginemos, em tese, apenas para fins didáticos, uma tragédia, por exemplo, a morte do Presidente e do Vice-Presidente. Nesse caso, os cargos serão declarados **vagos**.

O cargo também será declarado **vago**, tanto do Presidente como do Vice-Presidente, se deixarem de assumi-lo no prazo de 10 dias contados da data fixada para a **posse**, qual seja, 1.º de janeiro do ano seguinte ao da eleição (art. 82), salvo motivo de força maior (art. 78, parágrafo único, c/c o art. 79, *caput*).

Já estudamos que, ocorrendo *impedimento* ou *vaga* do cargo de Presidente da República, assumirá o Vice-Presidente, de modo temporário ou definitivo, neste caso, completando o mandato (**sucessor**, assumindo a titularidade do cargo).

E em caso de **impedimento**, tanto do Presidente como do Vice-Presidente, ou **vacância** dos respectivos cargos? Quem deverá assumi-los? Por qual período?

De acordo com o **art. 80**, serão **sucessivamente** chamados ao exercício da presidência, [13](#) nas hipóteses de **impedimento** do Presidente e do Vice ou de **vacância** dos respectivos cargos:

- o Presidente da Câmara dos Deputados;
- o Presidente do Senado Federal;
- o Presidente do STF.

Trata-se do que poderíamos chamar de **substitutos eventuais** ou **legais**. Havendo impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, por exemplo, em virtude de viagem de ambos, referidos substitutos eventuais assumem até o motivo do impedimento cessar.

Como exemplo, citamos, em razão de viagem do titular, do Vice-Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a assunção da Presidência da República pelo então Presidente do STF, **Min. Marco Aurélio de Mello**, que, de maneira bastante significativa, no exercício da Presidência, sancionou a **Lei n. 10.461/2002**, a qual, modificando a Lei n. 8.977/95 (“Lei do Cabo”), criou a **TV Justiça**, com sede no STF, em Brasília, e

que entrou no ar em 11.08.2002 e vem prestando relevante papel para toda a sociedade [14](#).

Observar, contudo, que a **assunção do cargo** por referidas pessoas (ao contrário do que ocorre no caso da vacância do cargo de Presidente e a sua sucessão pelo Vice, que o assume definitivamente) **será em caráter temporário (substitutos eventuais ou legais)**.

E como fica no âmbito estadual?

Em caso de impedimento ou de vacância do cargo de Governador de Estado, e diante da não assunção pelo Vice-Governador, serão chamados para governar, seguindo a simetria com o modelo fixado no art. 80:

- Presidente da Assembleia Legislativa;
- Presidente do TJ local.

E no Distrito Federal?

Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo:

- Presidente da Câmara Legislativa;
- Presidente do TJ do Distrito Federal e Territórios.

Interessante notar que essa regra está prevista expressamente no art. 93 da Lei Orgânica do DF, com a redação dada pela **Emenda n. 57/2010**, que aprimorou a regra que a *Emenda à LODF n. 37/2002* já havia dado ao art. 94. Isso porque a nova regra retira da linha sucessória de substituição o Vice-Presidente da Câmara Legislativa, seguindo simetricamente a regra do art. 80 da CF/88.

E como seria na hipótese de Municípios?

Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou de vacância dos respectivos cargos, será chamado para o exercício da Prefeitura:

- Presidente da Câmara Municipal;

■ e, em muitos casos, há a previsão de inclusão, na linha sucessória, do Vice-Presidente da Câmara Municipal (por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba etc.).

Não nos parece razoável, na hipótese de impedimento do Chefe do Legislativo local ou na situação de não assunção, que o Presidente do TJ assumira, já que não existe Judiciário municipal.

E como seria na hipótese de Governador de Território impedido ou vacância do cargo?

Como já estudamos no *item 7.8.6*, a direção dos Territórios, quando criados, dar-se-á por Governador **nomeado** pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal (art. 84, XIV).

Assim, apesar de não existirem leis disciplinando, entendemos que, nesse caso particular, o Presidente da República deveria nomear outro e, durante o processo, assumiria o Presidente da Câmara Territorial (art. 33, § 3.º — que estabelece: “a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa”).

■ 10.4.6.3. Mandato-tampão: eleição direta e indireta (art. 81)

Já vimos que os substitutos eventuais ou assumem o cargo no caso de **impedimento** do Presidente e do Vice, ou no caso de **vaga** de ambos os cargos.

Na primeira hipótese (**impedimento**), o afastamento foi apenas **temporário**. Na segunda, porém, no caso de **vaga** de ambos os cargos, esta será **definitiva** e, para não deixar o cargo vazio, duas situações surgem:

■ **vacância de ambos os cargos (de Presidente e de Vice) nos 2 primeiros anos do mandato:** de acordo com o art. 81, *caput*, far-se-á eleição **90 dias** depois de aberta a última vaga. Trata-se de **eleição direta**, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;

■ **vacância nos últimos 2 anos do mandato:** nessa hipótese, a eleição para ambos os cargos será feita **30 dias** depois da última vaga, pelo

Congresso Nacional, na forma da lei (art. 81, § 1.º). [15](#) Ou seja, **eleição indireta**! Exceção à regra do art. 14, *caput*, só permitida na medida em que introduzida pelo poder constituinte originário.

Durante o processo eleitoral e de transição, conforme mencionado, o cargo será exercido, temporariamente, pelos substitutos eventuais (art. 80). Após a nova eleição, nas duas situações (eleição quando a vaga se der no primeiro ou no segundo biênio do mandato presidencial) os eleitos (novo Presidente e novo Vice-Presidente da República) deverão apenas completar o período de seus antecessores (art. 81, § 2.º). Trata-se do denominado “**mandato-tampão**”.

E os Estados, podem legislar na hipótese de eleição indireta, definindo o procedimento, mesmo não havendo lei federal sobre o assunto?

O STF, no julgamento de pedido liminar formulado nas ADIs 4.298 e 4.309, assegurou a realização de **eleição indireta** pela Assembleia Legislativa do *Estado de Tocantins*, na medida em que o Governador e o vice foram cassados pelo TSE.

No caso, admitiu que, nos termos da Lei estadual n. 2.154/2009, a **votação** poderia ser **aberta**. O voto secreto é garantia do eleitor. Os parlamentares têm o dever de prestação de contas (princípio da publicidade) e, nesse sentido, reforçaram a ideia de votação aberta (ADI 4.298-MC e ADI 4.309-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.10.2009, Plenário, *DJE* de 27.11.2009, *Inf.* 562/STF).

O modelo federal, concluíram os Ministros, não é de observância compulsória (ADI 1.057) e, havendo previsão na Constituição estadual, poderia a Assembleia Legislativa local disciplinar a matéria, apesar da regra contida no art. 22, I (que fixa a competência da União para legislar sobre direito eleitoral). Isso porque, segundo o STF, não se trata de lei *materialmente eleitoral*, tendo em vista que apenas regula a sucessão “extravagante” do Chefe do Executivo (ADI 2.709).

É importante observar que, “... embora não deixem de revelar certa *conotação eleitoral*, porque dispõem sobre o procedimento de aquisição eletiva do poder político, **não** haveria como reconhecer ou atribuir características de direito eleitoral *stricto sensu* às normas que regem a *eleição indireta no caso de dupla vacância no último biênio do mandato*. Em última instância, essas leis

teriam por objeto **matéria político-administrativa** que demandaria típica decisão do **poder geral de autogoverno**, inerente à **autonomia política dos entes federados**. Em suma, a reserva de lei constante do art. 81, § 1.º, da CF, *nítida e especialíssima exceção ao cânone do exercício direto do sufrágio*, diria respeito *somente ao regime de dupla vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República*, e, como tal, da óbvia competência da *União*. Por sua vez, considerados o desenho federativo e a **inaplicabilidade do princípio da simetria** ao caso, competiria aos Estados-membros a definição e a regulamentação das normas de substituição de Governador e Vice-Governador. De modo que, **quando**, como na espécie, **tivesse o constituinte estadual reproduzido o preceito constitucional federal**, a **reserva de lei** não poderia deixar de se referir à **competência do próprio ente federado**. No mais, predefinido seu **caráter não eleitoral**, **não haveria se falar em ofensa ao princípio da anterioridade da lei eleitoral (CF, art. 16)**” (*Inf. 562/STF*).

Apenas para conhecimento, as eleições no Estado de Tocantins foram realizadas no dia **08.10.2009**, em Palmas, pela Assembleia Legislativa, e elegeram Governador e Vice para o exercício do **mandato-tampão** que terminou em 31.12.2010.

Também, interessante lembrar, diante da crise de moralidade que as instituições do **Distrito Federal** protagonizaram em 2010, em razão de escândalos levantados pela investigação da Polícia Federal denominada *Caixa de Pandora* (cf. *item 10.4.13*), a aprovação da **Emenda à Lei Orgânica n. 57, de 29.03.2010**, que, alterando o art. 94, § 1.º, passou a admitir, disciplinando a matéria, **eleição indireta**, pela Câmara Legislativa do DF, quando a vaga dos cargos de Governador e Vice-Governador do Distrito Federal se der nos últimos dois anos do mandato, deixando claro que, nessa hipótese, o novo Governador ou Vice-Governador eleito completará o mandato (**mandato-tampão**).

■ 10.4.6.4. Ausência do País do Presidente e do Vice-Presidente da República e licença do Congresso Nacional

Conforme acabamos de ver, a Constituição estabeleceu mecanismos para evitar a “**acefalia**” do Poder Executivo, seja por meio das atribuições do Vice-Presidente (que assume o cargo de modo temporário ou definitivo), seja na forma do art. 80, pelos Presidentes da CD, do SF ou do STF (de modo temporário).

O Estado não poderá ficar sem o comando no Executivo, tanto é assim que se estabelecem mecanismos de substituição e sucessão.

Por esse motivo (necessidade de liderança), nos termos do art. 83, o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, **sem licença do Congresso Nacional**, ausentar-se do País por período **superior a 15 dias**, sob pena de **perda do cargo**.

Naturalmente, durante o período de afastamento, o cargo será ocupado pelo Vice, ou, na forma do art. 80, pelos substitutos eventuais ou legais.

Tanto a previsão de substituição como a necessidade de autorização para o afastamento, bem como a consequência em caso de descumprimento, segundo o STF, são **normas de reprodução obrigatória** que, pela simetria, deverão ser integralmente reproduzidas no âmbito dos demais entes federativos.

Assim, o STF declarou inconstitucional dispositivo da *Constituição do Maranhão* que considerava desnecessária a substituição do Governador por seu Vice-Governador, quando se afastasse do Estado ou do País por até 15 dias (**ADI 3.647**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.09.2007, *DJE* de 16.05.2008).

Deixar o governo sem comando (já que o dispositivo atacado dispensava o preenchimento do cargo nos primeiros 15 dias) seria criar uma combatida “acefalia” no governo.

Nessa linha, o outro dispositivo que, em razão de reforma à Constituição estadual, retirava a sanção de **perda do cargo** (prevista no art. 83 da CF/88) também foi declarado inconstitucional, pois a referida consequência (perda do cargo) serve para dar sentido e garantia às regras de sucessão e de necessário preenchimento do cargo de Chefe do Poder Executivo.

■ 10.4.7. Ministros de Estado

■ 10.4.7.1. Características gerais e requisitos de investidura no cargo

Como já visto, os Ministros de Estado são meros auxiliares do Presidente da República no exercício do Poder Executivo e na direção superior da administração federal (arts. 76, 84, II, e 87).

Os Ministros de Estado dirigem Ministérios e são escolhidos pelo Presidente da República, que os nomeia, podendo ser demitidos (exonerados) a qualquer tempo, *ad nutum*, não tendo qualquer estabilidade (art. 84, I). Os requisitos para assumir o cargo de Ministro de Estado, cargo de **provimento em comissão**, são, de acordo com o art. 87, *caput*:

- ser brasileiro, nato ou naturalizado (exceto o cargo de **Ministro de Estado da Defesa**,¹⁶ que, de acordo com a **EC n. 23, de 02.09.1999**, deverá ser preenchido por **brasileiro nato**, conforme se observa pelo inciso VII do § 3.º do art. 12, acrescentado pela aludida emenda);
- ter mais de 21 anos de idade;
- estar no exercício dos direitos políticos.

■ 10.4.7.2. Atribuições dos Ministros de Estado

Competem aos Ministros de Estado, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei, as elencadas no parágrafo único do art. 87 da CF/88:

- exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República**;¹⁷
- expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;¹⁸
- apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

■ praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Disciplinando a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e cumprindo o previsto no art. 88 da CF, foi elaborada a Lei n. 9.649, de 27.05.1998, parcialmente revogada pela Lei n. 10.683/2003, que, por sua vez, foi alterada por diversos outros dispositivos.

Em comentário ao referido artigo, Bulos afirmava que “a lei ordinária prevista no art. 88 é *peculiar*, porque adentra na esfera de liberdade do presidente da República, a quem compete organizar a máquina administrativa *sponte propria*”. E já havia dito: “melhor seria deixar a matéria em aberto, como no direito anterior, sem as peias da lei para dispor sobre ministérios”. [19](#)

A **EC n. 32, de 11.09.2001**, alterou a redação do art. 88 da CF, nos seguintes termos: “a lei disporá sobre a **criação** e **extinção** de Ministérios e órgãos da administração pública”, **não** mais falando em **estruturação** e **atribuições**.

■ **10.4.7.3. Poderão os Ministros de Estado receber delegação para exercer matéria de competência privativa do Presidente da República?**

Como visto (cf. *item 10.4.2.1* e os detalhes da jurisprudência citada), o art. 84 enumera (trata-se de rol meramente exemplificativo) diversas atribuições do Presidente da República, ora com natureza de função de Chefe de Estado, ora com natureza de Chefe de Governo.

O parágrafo único do art. 84 dispõe que o Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos **Ministros de Estado** (bem como ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União), que deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações.

■ **10.4.7.4. Responsabilidade e juízo competente para processar e julgar os Ministros de Estado. A análise do controle político pela Câmara dos Deputados (art. 51, I)**

Os Ministros de Estado, sem prejuízo da previsão de outras condutas em legislação federal (cf., por exemplo, a Lei n. 1.079/50), de acordo com a Constituição, cometem crime de responsabilidade nas seguintes situações:

- a)** quando convocados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou qualquer de suas Comissões, para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado e inerentes às suas atribuições e deixarem de comparecer, salvo justificação adequada (arts. 50, *caput*, e 58, III);
- b)** quando as Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal encaminharem pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado e estes se recusarem a fornecê-las, não atenderem ao pedido no prazo de 30 dias, ou prestarem informações falsas (art. 50, § 2.º);
- c)** quando praticarem crimes de responsabilidade conexos e da mesma natureza com os crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República (art. 52, I, c/c o art. 85).

No caso de **crimes de responsabilidade** praticados **sem** qualquer **conexão** com o Presidente da República e nos **crimes comuns**, os Ministros de Estado serão processados e julgados perante o **STF**, nos exatos termos do art. 102, I, “c”. Na hipótese de crimes de responsabilidade conexos com os do Presidente da República o órgão julgador será o **Senado Federal**, nos termos do art. 52, I, e parágrafo único.

E a necessidade de autorização pela Câmara dos Deputados?

O art. 51, I, estabelece ser competência privativa da Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República, bem como contra os Ministros de Estado.

O STF interpretou que essa *condição de procedibilidade* ou *admissibilidade do processo* (por crime comum ou por crime de responsabilidade) só será exigida na hipótese de **crime de responsabilidade** praticado por Ministro de Estado **conexo** com aquele praticado pelo Presidente da República.

Assim, em se tratando de *crime comum* ou de *crime de responsabilidade*

praticado por Ministro de Estado sem conexão com o praticado pelo Presidente da República, não haverá necessidade de autorização pela Câmara dos Deputados, proibindo-se, portanto, a sua exigência. Nesse sentido, firme a jurisprudência do STF:

“EMENTA: O processo de *impeachment* dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo STF. Inaplicabilidade do disposto nos arts. 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1.079/1950, dado que é prescindível (ou seja, dispensada, acrescente-se) autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do MPF (CF, art. 129, I). Ilegitimidade ativa *ad causam* dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao *Parquet*” (Pet. 1.954, Rel. Min. Mauricio Corrêa, j. 11.09.2002, Plenário, DJ de 1.º.08.2003). [20](#)

■ 10.4.8. Conselho da República

O Conselho da República é **órgão superior de consulta** do Presidente da República e suas manifestações não terão, em hipótese alguma, caráter vinculatório aos atos a serem tomados pelo Presidente da República (art. 89, *caput*).

O Conselho da República se reúne quando **convocado** pelo Presidente da República, sendo por este último **presidido** (art. 84, XVIII). Dele participam: I — o Vice-Presidente da República; II — o Presidente da Câmara dos Deputados; III — o Presidente do Senado Federal; IV — os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; V — os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; VI — o Ministro da Justiça; [21](#) VII — **6** cidadãos brasileiros natos, com mais de **35** anos de idade, sendo **2** nomeados pelo Presidente da República, **2** eleitos pelo Senado Federal e **2** eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de **3** anos, vedada a recondução.

A Lei n. 8.041/90 regula a organização e o funcionamento do Conselho da República, cujas competências constitucionais foram definidas no sentido de se pronunciar sobre a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

■ 10.4.9. Conselho de Defesa Nacional

O Conselho de Defesa Nacional, também convocado e presidido pelo Presidente da República (art. 84, XVIII), é **órgão de consulta** deste nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático e dele participam, como **membros natos**: I — o Vice-Presidente da República; II — o Presidente da Câmara dos Deputados; III — o Presidente do Senado Federal; IV — o Ministro da Justiça; V — o **Ministro de Estado da Defesa**; [22](#) VI — o Ministro das Relações Exteriores; VII — o Ministro do Planejamento; VIII — os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica** [23](#) (art. 91).

A lei n. 8.183/91 regula a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional, competindo-lhe, nos termos da Constituição:

- **opinar** nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, bem como sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

- **propor** os critérios e as condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e **opinar** sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira [24](#) e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

- **estudar, propor e acompanhar** o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

■ 10.4.10. Crimes de responsabilidade

■ 10.4.10.1. Notas introdutórias e natureza jurídica

Os detentores de altos cargos públicos poderão praticar, além dos crimes comuns, os **crimes de responsabilidade**, vale dizer, infrações político-administrativas (crimes, portanto, de natureza **política**), submetendo-se ao processo de *impeachment*.

Historicamente, sob forte influência do modelo norte-americano, previu-se o crime de responsabilidade na Constituição de 1891, sendo originariamente regulamentado pelas Leis ns. 27 e 30, de 1892.

Na Constituição Federal de 1988, o **art. 85** prescreve que os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição serão considerados crimes de responsabilidade. **Exemplifica** como hipóteses de crime de responsabilidade os atos que atentarem contra: *a)* a existência da União; *b)* o livre-exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; *c)* o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; *d)* a segurança interna do País; *e)* a probidade na administração; *f)* a lei orçamentária; *g)* o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 85 dispõe que referidos crimes serão **definidos** em **lei especial**, que estabelecerá as **normas de processo e julgamento**.

Imprescindível, portanto, a existência de **lei especial** e **nacional** disciplinando as hipóteses de crimes de responsabilidade, lembrando que a regra geral do *princípio da legalidade* deve ser aqui evocada, no sentido de que *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*.

Aliás, o art. 5.º, XXXIX, da CF/88 determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Referida **lei especial** deve ser, necessariamente, votada pelo Congresso Nacional (lei federal), nos termos do art. 22, I, da CF/88.

Conforme decidiu o STF, “a definição das **condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade** e o **estabelecimento de regras que disciplinem**

o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da **competência legislativa privativa da União** e devem ser tratados em **lei nacional especial** (art. 85 da Constituição da República)” (ADI 2.220, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.11.2011, Plenário, *DJE* de 07.12.2011).

Não podemos deixar de lembrar, ainda, a S. 722/STF, convertida na **SV 46/STF** (j. 09.04.2015): “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da **competência legislativa privativa da União**”.

Nesse sentido, recepcionada, em grande parte, pela CF/88 (art. 85, parágrafo único), a **lei n. 1.079/50**, estabelecendo normas de processo e julgamento, foi alterada pela **Lei n. 10.028, de 19.10.2000**, que ampliou o rol das infrações político-administrativas, notadamente em relação aos **crimes contra a lei orçamentária**.

Esta última lei, inovando, permitiu, outrossim, empregando a expressão “ação penal” e impondo o rito da Lei n. 8.038/90, o oferecimento da denúncia por qualquer cidadão, inovação essa, segundo *Damásio de Jesus*, marcada pelo vício de **inconstitucionalidade**, em total afronta ao art. 129, I, da CF, devendo ocupar o seu lugar de destaque no “museu das imperfeições legislativas”. [25](#)

Além do Presidente da República (art. 52, I), também poderão ser responsabilizados politicamente e destituídos de seus cargos através do processo de *impeachment*: o Vice-Presidente da República (art. 52, I); os Ministros de Estado, nos crimes conexos com aqueles praticados pelo Presidente da República (art. 52, I); os Ministros do STF (art. 52, II); os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 52, II, nos termos da **EC n. 45/2004**); o Procurador-Geral da República (art. 52, II) e o Advogado-Geral da União (art. 52, II), bem como Governadores (*vide* esquema no *item 10.4.15*) e Prefeitos (art. 31 — Câmara dos Vereadores). [26](#)

■ 10.4.10.2. Procedimento

Concentraremos nossa análise no processo de *impeachment* definido na CF para o Presidente da República, seguindo as regras procedimentais descritas na Lei n. 1.079/50.

Tal **procedimento** é **bifásico**, composto por uma fase preambular, denominada **juízo de admissibilidade do processo**, na Câmara dos Deputados (**Tribunal de Pronúncia** — art. 80 da Lei n. 1.079/50), e por uma fase final, em que ocorrerão o **processo** propriamente dito e o **julgamento**, no Senado Federal (**Tribunal de Julgamento**).

■ 10.4.10.2.1. Câmara dos Deputados

A acusação poderá ser formalizada por qualquer **cidadão** no pleno gozo de seus direitos políticos.

A partir desse momento, o Presidente da República já passará a figurar na condição de acusado, sendo-lhe, portanto, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5.º, LV), podendo, então, acompanhar o procedimento e produzir provas.

A Câmara dos Deputados poderá, pela maioria qualificada de **2/3**, autorizar a instauração do processo, admitindo a acusação que está sendo imputada ao Presidente da República, para que seja **processado** e **julgado** perante o **Senado Federal** nos crimes de responsabilidade (art. 86, *caput*).

Dessa forma, as **indagações probatórias** deverão ser feitas perante o **Senado Federal**, que é o órgão que processa e julga Presidente da República nos crimes de responsabilidade, e não perante a Câmara, que verifica a procedibilidade da acusação.

Devemos alertar que a *jurisprudência do STF*, no julgamento de *impeachment* do Presidente da República, antes da apreciação pelo Plenário da Câmara dos Deputados (art. 52, I, da CF/88), conforme o art. 19 da Lei n. 1.079/50, vem reconhecendo, ao **Presidente da Câmara dos Deputados**, a competência para proceder a “... **exame liminar** da idoneidade da denúncia popular, ‘que não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da

legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode estender (...) à **rejeição imediata da acusação patentemente inepta** ou **despida de justa causa**, sujeitando-se ao controle do Plenário da Casa, mediante recurso (...)”.

MS 20.941-DF, Sepúlveda Pertence, *DJ* de 31.08.1992). [27](#)

Nesse procedimento de admissibilidade da denúncia (seja o liminar pelo seu Presidente, seja aquele realizado pelo Plenário), a Câmara dos Deputados profere **juízo político**, verificando, como anotou o STF, “... se a acusação é consistente, se tem ela base em alegações e fundamentos plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem razoável procedência, não sendo a acusação simplesmente fruto de quizílias ou desavenças políticas” (**MS 21.564**, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, j. 23.09.1992, Plenário, *DJ* de 27.08.1993).

■ 10.4.10.2.2. **Senado Federal**

Posteriormente, havendo autorização da Câmara dos Deputados, o Senado Federal **deverá** [28](#) instaurar o processo sob a presidência do **Presidente do STF**, submetendo o Presidente da República a julgamento (no Senado Federal), assegurando-lhe as garantias do contraditório e ampla defesa, podendo, ao final, absolvê-lo ou condená-lo pela prática do crime de responsabilidade.

Lembrar que, instaurado o processo, o Presidente ficará suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias. Se o julgamento não estiver concluído no aludido prazo, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo (art. 86, § 1.º, II, e § 2.º).

A sentença condenatória materializar-se-á mediante **resolução** do Senado Federal, que somente será proferida por 2/3 dos votos, limitando-se a condenação à **perda do cargo** e **inabilitação para o exercício de qualquer função pública** (tanto decorrentes de concurso público como de confiança ou de mandato eletivo) por **8 anos**, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único).

Dispõe o art. 15 da Lei n. 1.079/50 que “a denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente

o cargo”. O ex-Presidente Fernando Collor de Mello impetrou mandado de segurança alegando que a renúncia ao cargo extingiria o processo de *impeachment*. O STF, julgando o aludido MS 21.689-1, por maioria de votos, decidiu que a renúncia ao cargo não extingue o processo quando já iniciado.

Como vimos, na sistemática atual, ao contrário do que acontecia com as Leis ns. 27 e 30, de 1892, a condenação pelo crime de responsabilidade implicará a imposição de duas penas: a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos, sendo esta última não mais acessória, como era antes. Havendo renúncia ao cargo, quando já fora instaurado o processo, este deverá seguir até o final, podendo ser aplicada a pena da inabilitação, que é principal.

■ 10.4.10.3. Controle judicial?

O Poder Legislativo, seja a Câmara dos Deputados no juízo de admissibilidade, seja o Senado Federal no julgamento de mérito, realiza julgamento de **natureza política**, levando em consideração critérios de **conveniência** e **oportunidade**.²⁹

Assim, por esse aspecto (mérito), não nos parece razoável o controle judicial, sob pena de se violar o princípio da separação de poderes.

Cabe alertar, **contudo**, que a jurisprudência do STF vem admitindo o **controle judicial** em razão de **lesão** ou **ameaça a direito** (art. 5.º, XXXV, da CF/88), por exemplo, em procedimento que viole a ampla defesa, conforme se decidiu em vários precedentes (cf. MS 20.941-DF, MS 21.564-DF e MS 21.623-DF).

■ 10.4.11. Crimes comuns

■ 10.4.11.1. Conceito e procedimento

As regras procedimentais para o processamento dos crimes comuns estão previstas na Lei n. 8.038/90 e nos arts. 230 a 246 do *RISTF*.

Da mesma forma como ocorre nos crimes de responsabilidade, também haverá um controle político de admissibilidade, a ser realizado pela Câmara dos Deputados, que autorizará ou não o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF, através do voto de **2/3** de seus membros (art. 86, *caput*). [30](#)

Pois bem, admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o **STF** (crime comum).

A denúncia, nos casos de ação penal pública, será ofertada pelo **Procurador-Geral da República**. Em caso de não ter formado a sua *opinio delicti*, deverá requerer o arquivamento do inquérito policial. Nos casos de crime de ação privada, haverá necessidade de oferta da **queixa-crime** pelo ofendido, ou de quem por lei detenha tal competência.

A expressão “crime comum”, segundo posicionamento do STF, abrange “todas as modalidades de **infrações penais**, estendendo-se aos delitos eleitorais, alcançando até mesmo os crimes contra a vida e as próprias contravenções penais”. [31](#)

Recebida a denúncia ou queixa-crime, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções por 180 dias, sendo que, decorrido tal prazo sem o julgamento, voltará a exercê-las, devendo o processo continuar até decisão final.

■ 10.4.11.2. *Imunidade presidencial (irresponsabilidade penal relativa)*

De acordo com a regra do art. 86, § 4.º, o Presidente da República, durante a vigência do mandato, **não** poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Dessa forma, ele **só** poderá ser responsabilizado (e entenda-se a responsabilização pela prática de **infração penal comum — ilícitos penais**) por **atos praticados em razão do exercício de suas funções** (*in officio* ou *propter officium*).

Assim, as **infrações penais** praticadas antes do início do mandato ou durante a sua vigência, porém sem qualquer relação com a função presidencial (ou seja, não praticadas *in officio* ou *propter officium*), **não** poderão ser objeto da *persecutio criminis*, que ficará, **provisoriamente**, **inibida**, acarretando, logicamente, a suspensão do curso da prescrição. Trata-se da **irresponsabilidade penal relativa**, pois a imunidade só abrange ilícitos penais praticados antes do mandato, ou durante, sem relação funcional.

No tocante às infrações de natureza **civil**, **política** (*crimes de responsabilidade*), **administrativa**, **fiscal** ou **tributária**, **poderá** o Presidente da República ser responsabilizado, pois a imunidade (irresponsabilidade penal relativa) restringe-se apenas à *persecutio criminis* por ilícitos penais que não tenham sido cometidos *in officio* ou *propter officium*, como vimos. Quando praticados em relação à função presidencial, aí sim poderá o Presidente da República sofrer a persecução penal.

Por fim, observar que, oferecida a denúncia no STF, havendo autorização da Câmara, julgando-se procedente o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, a condenação aplicada será a prevista no tipo penal, e não a perda do cargo (como pena principal), que só ocorrerá no caso de crime de responsabilidade.

No caso de crime comum, a perda do cargo dar-se-á por via reflexa, em decorrência da suspensão temporária dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da sentença criminal condenatória, transitada em julgado. [32](#)

■ 10.4.12. Prisão

Nos termos do art. 86, § 3.º, enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.

■ 10.4.13. A imunidade formal relativa à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa podem ser estendidas aos demais chefes do Poder Executivo por leis dos respectivos entes federativos?

Não.

Consoante interpretação do STF, as regras sobre a imunidade formal em relação à **prisão** (art. 86, § 3.º), bem como aquelas relacionadas à **imunidade penal relativa** (art. 86, § 4.º), estabelecidas para o Presidente da República, **não** podem ser estendidas aos Governadores de Estado e, no mesmo sentido, ao Governador do DF e Prefeitos por atos normativos próprios, na medida em que referidas prerrogativas (que são regras derogatórias do direito comum) estão reservadas à **competência exclusiva da União** para disciplinar, nos termos do art. 22, I (direito processual). Nesse sentido:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade — Constituição do Estado do Pernambuco — Outorga de prerrogativa de caráter processual penal ao Governador do Estado — Imunidade a prisão cautelar — Inadmissibilidade — Usurpação de competência legislativa da União — Prerrogativa inerente ao Presidente da República enquanto Chefe de Estado (CF/88, art. 86, § 3.º) — Ação direta procedente. Imunidade a prisão cautelar — prerrogativa do Presidente da República — impossibilidade de sua extensão, mediante norma da Constituição estadual, ao Governador do Estado. O Estado-membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao Governador a prerrogativa extraordinária da imunidade a **prisão em flagrante**, a **prisão preventiva** e a **prisão temporária**, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete-se, com **exclusividade**, ao **poder normativo da União Federal**, por efeito de expressa **reserva constitucional de competência** definida pela Carta da República. — A norma constante da Constituição estadual — que impede a prisão do Governador de Estado antes de sua condenação penal definitiva — não se reveste de validade jurídica e, consequentemente, não pode subsistir em face de sua evidente incompatibilidade com o texto da Constituição Federal. PRERROGATIVAS INERENTES AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENQUANTO CHEFE DE ESTADO. Os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias Constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos no art. 86, §§ 3.º e 4.º, da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei Fundamental — por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de Chefe de

Estado — são apenas extensíveis ao Presidente da República. Precedente: **ADI 978-PB**, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello” (**ADI 1.028**, j. 19.10.1995, *DJ* de 17.11.1995. Cf., ainda, ADI 1.634-MC). (Em idêntico sentido, cf. **ADI 1.020**, j. 19.10.1995, para a situação particular do DF. Para um amplo debate, cf. **HC 102.732**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.03.2010, Plenário, *DJE* de 07.05.2010).

Em virtude desse entendimento firmado pelo STF, para se ter um exemplo de desdobramento, a Câmara Legislativa do DF, envolta em clima de turbulência política, deflagrada pela investigação e pelos fatos levantados pela *Operação Caixa de Pandora*, aprovou a **Emenda à Lei Orgânica n. 57, de 29.03.2010**, revogando os §§ 3.º e 4.º do art. 103, que, “copiando” o art. 86, §§ 3.º e 4.º, da CF/88, conferiam *imunidade formal relativa à prisão* e instituíam *cláusula de irresponsabilidade penal relativa* para o Governador do DF, já declaradas inconstitucionais pelo STF na **ADI 1.020**.

■ 10.4.14. Outras regras importantes sobre os demais Chefes do Poder Executivo

■ 10.4.14.1. Os demais entes federativos podem dispor sobre crime de responsabilidade definindo o órgão julgador por ato legislativo próprio?

A pergunta colocada nesse item busca saber se os Estados-Membros, o DF e os Municípios podem legislar sobre crime de responsabilidade, estabelecendo o órgão julgador?

Não.

Esse tema tem sido muito debatido na medida em que vários Estados-Membros fixaram, seguindo o modelo federal, o Poder Legislativo local, no caso a Assembleia Legislativa, como sendo o órgão competente para processar e julgar os Governadores por crime de responsabilidade.

Em vários precedentes, o STF entendeu como **inconstitucional** essa

previsão, na medida em que a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é da União (art. 22, I) que, no caso, o fez, nos termos da Lei n. 1.079/50 (cf. S. 722/STF e ADIs 4.791, 4.792 e 4.800, j. 12.02.2015).

De acordo com o art. 78, § 3.º, da referida lei, os Governadores de Estado serão julgados por um dito “Tribunal Especial”, composto de 5 membros do Legislativo e de 5 desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate.

■ **10.4.14.2. Os demais entes federativos podem estabelecer a licença prévia pelo legislativo local para o julgamento dos Chefes do Executivo?**

Em outras palavras, o **art. 51, I, da CF/88** pode ser aplicado por **simetria** no âmbito estadual, distrital e municipal?

Sim.

Lembramos a existência de vários precedentes envolvendo os **Governadores de Estado** e, no caso, o reconhecimento da **constitucionalidade** de normas estabelecidas nas Constituições estaduais exigindo a autorização prévia de dois terços da Assembleia Legislativa como requisito indispensável para se admitir a acusação nas ações por crimes comum e de responsabilidade (**licença prévia**) contra os Chefes dos Executivos estaduais. Nesse sentido, destacamos o seguinte julgado:

“EMENTA: Governador de Estado: processo por crime comum: competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. 1. A transferência para o STJ da competência originária para o processo por crime comum contra os Governadores, ao invés de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da Assembleia Legislativa para a sua instauração: se, no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o Presidente da República finca raízes no princípio da independência dos poderes centrais, à mesma inspiração se soma o **dogma da**

autonomia do Estado-membro perante a União, quando se cuida de confiar a própria subsistência do mandato do Governador do primeiro a um órgão judiciário federal. 2. A necessidade da autorização prévia da Assembleia Legislativa não traz o risco, quando negadas, de propiciar a impunidade dos delitos dos Governadores: a denegação traduz simples **obstáculo temporário ao curso de ação penal, que implica, enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional**. 3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 159.230, Plenário, j. 28.03.94; HC 80.511, 2.^a T., j. 21.08.2001). 4. A autorização da Assembleia Legislativa há de preceder à decisão sobre o recebimento ou não da denúncia ou da queixa. 5. Com relação aos Governadores de Estado, a orientação do Tribunal **não é afetada pela superveniência da EC 35/2001**, que aboliu a exigência da licença prévia antes exigida para o processo contra **membros do Congresso Nacional**, alteração que, por força do art. 27, § 1.º, da Constituição alcança, nas unidades federadas, os Deputados Estaduais ou Distritais, mas não os Governadores” (HC 86.015, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16.08.2005, 1.^a T., DJ de 02.09.2005).

Devemos deixar claro que, para o STF, o **marco interruptivo da prescrição** é a data do despacho que solicita a anuência do Poder Legislativo local para a instalação do processo, quando estabelecida essa exigência, e não a data da efetiva manifestação, o que, de certa forma, minimiza os riscos das incontroláveis manobras políticas (Inq 457, j. 10.02.93).

Outro ponto de suma importância foi a definição de que “o controle político exercido pelas Assembleias Legislativas sobre a admissibilidade das acusações endereçadas contra governadores **não conferiria aos parlamentos locais a autoridade para decidir sobre atos constritivos acessórios à investigação penal, entre eles as prisões cautelares**” (Inf. 774/STF — ADIs 4.791, 4.792 e 4.800, j. 12.02.2015).

Essa questão foi **amplamente discutida** no julgamento do HC 102.732 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.03.2010), impetrado pelo ex-Governador do Distrito Federal, *José Roberto Arruda*, contra ato do STJ que decretou a sua **prisão preventiva** por suposta tentativa de suborno a testemunha no Inq. 650, que

tramitava perante aquele Superior Tribunal e investigava suposto esquema de corrupção no DF, consistente em alegada organização criminosa para o desvio e a apropriação de verbas públicas (a denominada *Operação Caixa de Pandora*, deflagrada pela *Polícia Federal* em 27.11.2009).

A decretação da **prisão preventiva** do então Governador do DF teve por fundamento o art. 312 do CPP, sob a alegação de que a tentativa de coação de testemunha, objetivando interferir em seu depoimento, acabava prejudicando a instrução criminal.

Em referido julgamento, por 9 x 1, o STF **denegou** a ordem de *habeas corpus*, entendendo como perfeita a prisão cautelar do Governador de Estado, restringindo a exigência da sentença final condenatória transitada em julgado exclusivamente para o Presidente da República.

Finalmente, exposta a atual jurisprudência da Corte (e, portanto, **a orientação para as fases preambulares dos concursos públicos**), não podemos deixar de consignar a nossa insatisfação com esse entendimento, que, sem dúvida, em muitos casos, serve de verdadeira **blindagem** em razão da pressão política que essas autoridades podem exercer no âmbito do legislativo local.

Entendemos que a previsão da licença prévia não encontra fundamento na Constituição em relação ao **crime comum** praticado pelo Governador, na medida em que o art. 105, I, da CF/88 não faz essa exigência e, assim, não cabe ao legislador criar esse requisito de procedibilidade.

Em relação ao **crime de responsabilidade**, sustentamos a necessidade de lei federal, por entendermos tratar-se de regra processual (lembramos a existência de alguns posicionamentos admitindo a competência do legislador estadual — cf. voto do Min. Marco Aurélio nas ADIs 4.791, 4.792 e 4.800, j. 12.02.2015).

Sobre o tema da licença prévia, destacamos que o constituinte originário de 1988 estabeleceu a sua exigência para o processo e julgamento dos parlamentares federais, extensível aos estaduais, formalidade que veio a ser abolida pela EC n. 35/2001. Como não havia previsão dessa exigência para os Governadores, não havia sentido uma emenda constitucional para a hipótese dos

Chefes do Poder Executivo. Assim, em nosso entender, a Constituição de 1988 não autoriza a criação dessa exigência por ato normativo estadual, distrital ou local.

Contudo, conforme vimos, essa não é a posição do STF que, inclusive, veio a ser confirmada no julgamento das ADIs 4.791, 4.792 e 4.800 (j. 12.02.2015), reconhecendo a **constitucionalidade de regra da licença prévia para o julgamento de governador de Estado tanto para o crime comum como para o de responsabilidade**.

Alertamos que o Min. Marco Aurélio ficou vencido e os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso sinalizaram a necessidade de se rever o atual entendimento da Corte, muito embora tenham seguido a atual jurisprudência.

O Min. Roberto Barroso reconheceu a constrangedora inconveniência política e moral da regra da licença prévia, que, contudo, ainda não se caracterizava como inconstitucionalidade.

Devemos lembrar que tramita no Senado Federal a **PEC 6/2010** prescrevendo que a instauração de processo criminal contra Governador de Estado ou do DF independe de autorização legislativa. Sem dúvida, um grande avanço para a sociedade quando se tornar realidade (**pendente**).

■ **10.4.15. Sistematização da competência para julgamento das autoridades pela prática de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade**

Trata-se de competência por **prerrogativa de função**, que deverá ser mais bem estudada em processo penal. Por ora, limitamo-nos a sistematizar o foro competente quando praticado o crime comum ou de responsabilidade por algumas autoridades:

■ **Presidente e Vice-Presidente da República:** *a*) infração penal comum STF (art. 102, I, “b”); *b*) crime de responsabilidade Senado Federal (art. 52, I);

■ **Ministro de Estado:** *a*) infração penal comum e responsabilidade

STF (art. 102, I, “c”); *b*) crime de responsabilidade conexo com o praticado pelo Presidente da República Senado Federal (art. 52, I);

■ **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica:** *a*) infração penal comum e responsabilidade STF (art. 102, I, “c”); *b*) crime de responsabilidade conexo com o praticado pelo Presidente da República Senado Federal (art. 52, I); [33](#)

■ **Ministro do STF:** *a*) infração penal comum STF (art. 102, I, “b”); *b*) crime de responsabilidade Senado Federal (art. 52, II);

■ **Membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público:** *a*) infração penal comum a competência será fixada individualmente, de acordo com o cargo de origem de cada membro dos Conselhos (a PEC Paralela da Reforma do Judiciário, que precisa ainda ser aprovada, estabelece a competência do STF, mas isso, como se disse, depende de aprovação pelo CN); *b*) crime de responsabilidade Senado Federal (art. 52, II — EC n. 45/2004);

■ **Procurador-Geral da República:** *a*) infração penal comum STF (art. 102, I, “b”); *b*) crime de responsabilidade Senado Federal (art. 52, II);

■ **Advogado-Geral da União:** *a*) infração penal comum STF (art. 102, I, “c”); [34](#); *b*) crime de responsabilidade Senado Federal (art. 52, II);

■ **Deputados Federais e Senadores:** *a*) infração penal comum, desde a expedição do diploma STF (arts. 102, I, “b”, e 53, § 1.º); *b*) crime de responsabilidade Casa correspondente (art. 55, § 2.º);

■ **Membros dos tribunais superiores (STJ, TSE, TST e STM), do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente:** infração penal comum e crime de responsabilidade STF (art. 102, I, “c”);

■ **Desembargadores dos TJs dos Estados e do Distrito Federal; membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; membros dos TRFs, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e do**

Ministério Público da União que oficiem perante tribunais:[35](#) infração penal comum e crime de responsabilidade STJ (art. 105, I, “a”);

■ **Juizes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, e membros do MP da União (Federal, do Trabalho, Militar, do DF e Territórios)**[36](#) — art. 128, I): infração penal comum e crime de responsabilidade TRF da área de jurisdição (art. 108, I, “a”). Importante notar que, se o membro do MP da União atuar perante tribunais, a competência se desloca para o STJ, como visto acima. No entanto, atuando em **primeira instância**, a competência por prerrogativa de função é do **TRF** (cf. HC 73.801/MG, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 27.06.1997, p. 30226, 1.^a Turma);

■ **Governador de Estado:** *a*) infração penal comum STJ (art. 105, I, “a”); *b*) crime de responsabilidade Tribunal Especial, previsto na Lei n. 1.079/50 (lei nacional federal — cf. ADI 2.220);[37](#)

■ **Vice-Governador de Estado:** *a*) infração penal comum dependerá da Constituição Estadual, sendo, em regra, a competência do TJ; *b*) crime de responsabilidade depende de lei federal;

■ **Procurador-Geral de Justiça:** *a*) infração penal comum TJ (art. 96, III); *b*) crime de responsabilidade Poder Legislativo Estadual (art. 128, § 4.º);

■ **juizes estaduais e do Distrito Federal e Territórios; membros do Ministério Público Estadual:** infração penal comum e crime de responsabilidade TJ, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, ou seja, crime eleitoral TRE (art. 96, III);

■ **deputado estadual:** *a*) infração penal comum depende da CE. No caso de São Paulo, e como regra geral, o TJ (art. 74, I, da CE/SP); *b*) crime de responsabilidade Poder Legislativo Estadual (Assembleia Legislativa — art. 27, § 3.º, da CF/88);

■ **prefeito:** *a*) infração penal comum TJ (art. 29, X); *b*) crime de responsabilidade (natureza criminal) TJ (art. 29, X, c/c o art. 1.º do Decreto-lei n. 201/67); *c*) crime de responsabilidade (natureza de infração político-administrativa) Câmara dos Vereadores (art. 31, c/c o art. 4.º do Decreto-lei n. 201/67); *d*) crime federal TRF; *e*) crime eleitoral TRE.

■ **Presidente da Câmara Municipal:** o § 1.º do art. 29-A, acrescentado pela **EC n. 25/2000**, dispõe que a Câmara Municipal não gastará mais de **70%** de sua **receita** com a **folha de pagamentos**, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. O desrespeito a essa regra, conforme o § 3.º do referido artigo, constitui **crime de responsabilidade** do **Presidente da Câmara Municipal**.

■ **10.4.15.1. Prefeitos Municipais**

No tocante à **competência por prerrogativa de função** dos **Prefeitos Municipais**, convém nos determos um pouco mais na questão, em face de suas especificidades.

O Prefeito, como as demais autoridades públicas analisadas, pode cometer tanto crime **comum** como de **responsabilidade**.

Desde já, como estudamos, e, mais uma vez, valendo-nos das lições de Damásio de Jesus, [38](#) existem crimes de responsabilidade em **sentido amplo** (“a locução abrange tipos criminais propriamente ditos e fatos que lesam deveres funcionais, sujeitos a sanções políticas”) e em **sentido estrito** (“abrange delitos cujos fatos contêm violação dos deveres de cargo ou função, apenados com sanção criminal”), estando estes últimos previstos tanto no CP como em legislação especial.

Destaca-se, então, a existência de **crime de responsabilidade próprio** (ou em **sentido estrito** — constitui **delito**, configurando **infração penal**) e **crime de responsabilidade impróprio (ilícito político-administrativo)**, que, segundo o mestre, trata-se de “crime que não é crime”.

Como regra geral, portanto, o Prefeito será julgado pelo **TJ local**, nas hipóteses de **crime comum** (art. 29, X, da CF); pela **Câmara Municipal**, nos **crimes de responsabilidade** (art. 31 da CF); pelo **TRE**, nos **crimes eleitorais**, e pelo **TRF**, nos **crimes federais** (art. 109, IV, da CF). Nesse sentido a **S. 702/STF**: “a competência do **TJ** para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de competência da **Justiça comum estadual**; nos demais casos, a competência

originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau”. Surgem, contudo, algumas particularidades.

Analisemos, primeiro, os **crimes comuns**:

■ **competência originária do TJ**: o STF entendeu que o julgamento poderá dar-se tanto pelo **Plenário** como por **órgão fracionário**, por exemplo, uma das Câmaras Criminais do Tribunal (cf. STF, HC 71.381-5/RS, Rel. Min. Moreira Alves, 1.^a Turma, *DJ* de 1.º.03.1996, p. 5009), ou mesmo pelo **Órgão Especial**, sendo a competência fixada internamente, pelo RI do Tribunal;

■ **crimes dolosos contra a vida**: afasta-se a regra geral do art. 5.º, XXXVIII, aplicando-se a do art. 29, X, de maior especialidade. Logo, Prefeitos são julgados perante o **TJ** também nos crimes dolosos contra a vida;

■ **crimes comuns tipificados no art. 1.º do Decreto-lei n. 201/67**: competência originária do **TJ**, na medida em que referidas tipificações têm **natureza criminal**. **IMPORTANTE**: o mencionado Decreto-lei foi alterado pela **Lei n. 10.028, de 19.10.2000**, trazendo diversas outras tipificações penais ao art. 1.º, nos incisos XVII a XXIII;

■ **crimes funcionais descritos no CP**: cometidos por funcionários públicos no exercício do cargo ou função e descritos, consoante enumeração do Professor Damásio, nos arts. 150, § 2.º; 300; 301; 312 a 326 e 359-A a 359-H, estes últimos acrescentados pela **Lei n. 10.028, de 19.10.2000**, todos do CP. Muito embora se fale em crime de responsabilidade, são tomados em sentido estrito, caracterizando infração penal e, portanto, atraindo a competência do **TJ**, por força do art. 29, X, da CF;

■ **abuso de autoridade**: crime previsto na Lei n. 4.898, de 09.12.1965 — **TJ**;

■ **crime de Prefeito em detrimento de bens, serviços ou interesses do Município**: a competência é do **TJ**. Como exemplo, lembramos: **a)** o desvio de verba federal repassada ao Município, já que, ainda que proveniente de entidade federal, passou ao **patrimônio da**

Municipalidade (RECr 77.893/GO, DJ de 24.05.1994, p. 3528); **b)** desvio de verbas federais, repassadas ao Município, em razão de convênio firmado com a União Federal e o INAMPS não constitui crime contra a União ou autarquia federal, mas contra o Município, já que as verbas, uma vez repassadas, passaram a integrar o **patrimônio e receitas do Município**, sendo o Município o sujeito passivo e não a União (*vide* S. 133 do extinto TFR). Consolidando esse entendimento, a **S. 209/STJ**: “competete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”;

■ **crime de Prefeito em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, empresas públicas e autarquias federais, além da malversação de verbas recebidas da União sob condição e sujeitas à prestação de contas e ao controle do TCU**: a regra, agora, é outra: competência do **TRF**, e não do TJ, de acordo com o art. 109, IV, da CF. Como exemplo, lembramos: **a)** desvio de verbas concedidas a Município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sujeitas à prestação de contas ao Ministério da Educação e a julgamento pelo **TCU** (HC 68.967-PR — DJU de 16.04.1993); **b)** desvio de verbas públicas federais, oriundas do FUNDEF, FNDE e FPM e sujeitas ao controle do **TCU** (HC 80.867, 18.12.2001); **c)** prática de fraude contra o FGTS em benefício próprio. Nesses termos, a **S. 208/STJ**: “competete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal” (cf. HC 68.967-1/PR, Pleno, STF, Rel. Min. Ilmar Galvão). **CUIDADO**: mudança de entendimento no **STJ**. Conforme ficou consignado no julgamento da CC 123.817, “após o julgamento do CC 119.305/SP, a 3.^a Seção desta Corte, **mudando a jurisprudência até então pacificada**, passou a entender ser da competência da **Justiça Federal** a apuração, no âmbito penal, de malversação de verbas públicas oriundas do **FUNDEF**, **independentemente da complementação de verbas federais**, diante do **caráter nacional da política de educação**, o que evidencia o **interesse da União** na correta aplicação dos recursos” (j. 12.09.2012 — pendente de análise pelo STF);

■ **crimes eleitorais**: a competência originária é do **TRE**;

■ **ações de natureza civil:** as de natureza civil, vale dizer, quando não se estiver julgando infração criminal praticada pelo Prefeito, não gozam do foro privilegiado do TJ, previsto no art. 29, X, da CF. Assim, as ações populares movidas em face dos Prefeitos, ações civis públicas, ações que julgam responsabilidade civil por atos praticados pelo Prefeito no exercício do cargo, ações envolvendo matéria relativa à improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92) **não são apreciadas pelo TJ** em sede de competência originária, devendo ser ajuizadas em 1.º grau de jurisdição, observadas as regras de organização judiciária.

Em relação à **improbidade administrativa**, contudo, a **Lei n. 10.628/2002**, em nosso entender, de modo inconstitucional, dando nova redação ao art. 84, § 2.º, do CPP, estabeleceu que a ação de improbidade administrativa, de que trata a Lei n. 8.429/92, seria proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou a autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, ainda que o inquérito ou a ação judicial fossem iniciados após a cessação do exercício da função pública. Felizmente, de maneira acertada, o **STF declarou inconstitucional** a pretendida regra (cf. discussão no *item 10.4.15.3* e perspectivas do julgamento da PET 3.240 AgR — **pendente** — com possibilidade de alteração do entendimento, conforme indicamos no *item 10.4.15.5*).

Vejamos, agora, os **crimes de responsabilidade**, infrações político-administrativas:

■ **art. 4.º do Decreto-lei n. 201/67:** julgamento pela **Câmara Municipal**;

■ **EC n. 25, de 14.02.2000:** o **Prefeito Municipal** cometerá crime de responsabilidade (infração político-administrativa) caso deixe de efetuar o repasse dos valores para o Poder Legislativo, de acordo com as regras fixadas no art. 29-A, § 2.º, I, II e III, ou seja: **a)** efetuar repasse que supere os limites fixados no art. 29-A; **b)** não enviar o referido repasse até o dia **20** de cada mês; **c)** enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Muito embora referida EC tenha entrado em vigor em **1.º.01.2001**, entendemos necessária a **previsão legal**, tipificando referidas hipóteses, sob pena de se ferir o princípio constitucional do

nullum crimen nulla poena sine praevia lege. A lei, por todo o exposto, só poderá definir a competência da **Câmara Municipal** para o julgamento da infração político-administrativa, cometida pelo Prefeito Municipal.

■ 10.4.15.2. Vereadores Municipais

Alexandre de Moraes ressalta que “... não existe qualquer possibilidade de criação pelas Constituições Estaduais, nem pelas respectivas leis orgânicas dos municípios, de imunidades formais em relação aos vereadores, e tampouco de ampliação da imunidade material, uma vez que a competência para legislar sobre direito civil, penal e processual é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. Diversa, porém, é a hipótese de previsão de foro privilegiado para o processo e julgamento dos vereadores. Em face do art. 125, § 1.º, da Constituição Federal, não existirá óbice à Constituição estadual em prever o Tribunal de Justiça como o juízo competente para os processos e julgamentos dos vereadores nas infrações penais comuns, se assim o legislador constituinte preferir”.³⁹

No que concerne aos **crimes dolosos contra a vida**, porém, o STF já decidiu pela impossibilidade de julgamento por outro órgão, como o TJ, quando não houver expressa previsão da exceção na própria CF, não se aplicando, portanto, a regra acima exposta decorrente da aludida interpretação conferida ao art. 125, § 1.º. Logo, de acordo com entendimento do STF, os **Vereadores** serão julgados pelo **Tribunal do Júri** na hipótese de crimes dolosos contra a vida.⁴⁰ Nesses termos, o conteúdo da S. 721/STF, convertida na **SV 45/STF** (j. 08.04.2015): “a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual”.

Em se tratando de **crimes de responsabilidade** (*infração político-administrativa*), a nosso ver a competência será da **Câmara Municipal**.

Cabe alertar que, em relação aos **crimes comuns** (exceto **dolosos contra a vida**) e de **responsabilidade** (*de natureza criminal*), malgrado o

posicionamento de Alexandre de Moraes admitindo julgamento pelo **TJ**, desde que haja expressa previsão na CE, corroborado por decisão de 1996 da 2.^a Turma do STF,⁴¹ vêm sendo percebidas algumas decisões contrárias no STJ, no sentido de ser privativa da União a competência para legislar sobre processo penal. Ao que se tem conhecimento, o plenário do STF ainda não pacificou essa questão, ficando aberta a discussão.⁴² Ressalte-se, contudo, a previsão para julgamento dos **Vereadores** pelo **TJ/SP**, de acordo com o **Provimento n. 51/98**.

■ **10.4.15.3. A inconstitucionalidade das regras trazidas pela Lei n. 10.628/2002 em relação à “perpetuatio jurisdictionis” e ao “inusitado foro cível por prerrogativa de função em lei processual penal”**

Como já apontamos neste trabalho, a **Lei n. 10.628, de 24.12.2002**, fixou novas regras de **competência por prerrogativa de função**, alterando a redação do art. 84 do CPP.

Nos termos do *caput* do aludido dispositivo legal, a competência por prerrogativa de função é do STF, do STJ, dos TRFs e TJs dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.

Até **25.08.1999**, conforme vimos, prevalecia o entendimento no STF exposto na orientação dada pela **Súmula 394**, consagrando o foro especial para ocupantes de cargos públicos: “cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”. No julgamento da questão de ordem no **Inquérito n. 687-SP**, o STF **cancelou a Súmula 394**.

A **Lei n. 10.628, de 24.12.2002**, todavia, dando nova redação ao art. 84 do CPP, além de criar uma espécie de *foro cível por prerrogativa de função* em lei processual penal, “ressuscitou” a já banida e execrada regra da *perpetuatio jurisdictionis* após o término do exercício do cargo ou função pública, seja criminal, seja, agora, também, civil, no caso da ação de improbidade

administrativa de que trata a Lei n. 8.429/92.

Conforme já estudamos (cf. *item 9.9.2.3*), buscando declarar inconstitucional o novo dispositivo, foram propostas a **ADI 2.797**, ajuizada em 27.12.2002 pela *Associação Nacional dos Membros do MP (CONAMP)* e que teve o seu pedido de liminar negado pelo STF (07.01.2003), e a **ADI 2.860**, proposta pela *Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)*, distribuída por prevenção, em 25.03.2003, àquela primeira ajuizada pela CONAMP.

O STF, em algumas Reclamações, havia determinado a permanência em vigor da nova regra do art. 84 do CPP até o julgamento definitivo das ADIs ajuizadas (Rcl 2.381 AgR/MG, Rel. Min. Carlos Britto, 06.11.2003 e *Inf. 328/STF*).

Apreciando as duas ADIs, a Suprema Corte julgou **inconstitucional** a nova regra. “... Entendeu-se que o § 1.º do art. 84 do CPP, além de ter feito interpretação autêntica da Carta Magna, o que seria reservado à norma de hierarquia constitucional, **usurpou** a competência do STF como guardião da Constituição Federal ao inverter a leitura por ele já feita de norma constitucional, o que, se admitido, implicaria submeter a interpretação constitucional do Supremo ao referendo do legislador ordinário. Considerando, ademais, que o § 2.º do art. 84 do CPP veiculou duas regras — a que estende, à ação de improbidade administrativa, a competência especial por prerrogativa de função para inquérito e ação penais e a que manda aplicar, em relação à mesma ação de improbidade, a previsão do § 1.º do citado artigo —, concluiu-se que a primeira resultaria na criação de nova hipótese de competência originária não prevista no rol taxativo da Constituição Federal, e a segunda estaria atingida por arrastamento. Ressaltou-se, ademais, que a ação de improbidade administrativa é de natureza civil, conforme se depreende do § 4.º do art. 37 da CF, e que o STF jamais entendeu ser competente para o conhecimento de ações civis, por ato de ofício, ajuizadas contra as autoridades para cujo processo penal o seria” (*Inf. 401/STF* e *Notícias STF*, 15.09.2005 — **ADI 2.797** e **ADI 2.860**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.09.2005, Plenário, *DJ* de 19.12.2006. No mesmo sentido: Pet 3.030-QO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.05.2012, Plenário, *Inf. 667/STF*).

Finalmente, em 17.05.2012, foram **acolhidos** os **embargos declaratórios** opostos pelo Procurador-Geral da República na ADI 2.797, estabelecendo-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1.º e 2.º do art. 84 do CPP, inseridos pelo art. 1.º da Lei 10.628/2002, terão **eficácia a partir de 15.09.2005** (ADI 2.797-ED, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, j. 17.05.2012, Plenário, *Inf.* 666/STF).

Isso porque, na medida em que a regra trazida pela Lei n. 10.628/2002 vigorou por quase 3 anos (de 24.12.2002, data de sua vigência, até a sua nulificação, em 15.09.2005, quando foram apreciadas as ADIs 2.797 e 2.860), reconheceu-se a necessidade de se **preservar** a validade dos atos praticados com base na referida lei e, assim, adotou-se a técnica da **modulação dos efeitos da decisão**, estabelecendo-se que o efeito da declaração de inconstitucionalidade valeria a partir da decisão (efeito *ex nunc*), ou seja, a partir de 15.09.2005, sem contudo, *em verdadeiro entendimento defensivo*, admitir o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal dos processos que ainda estavam em curso.

■ 10.4.15.4. *Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento*

Como se sabe, as prerrogativas de foro são definidas pela Constituição em relação às autoridades no exercício efetivo da função. Assim, de acordo com o entendimento fixado pela Corte, por exemplo, um ex-parlamentar não teria mais a referida prerrogativa com o término do seu mandato (cf. *item 9.9.2.3* e as suas particularidades).

Entretanto, consoante a **S. 704/STF**, “não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”. Para se ter um exemplo, imaginemos os crimes de quadrilha, peculato e apropriação indébita imputados a **juiz de direito**, serventuários da Justiça e advogados. Em face dos princípios da conexão e continência e tendo

em vista, ainda, a jurisdição de maior graduação (art. 78, III, do CPP), nos termos do **art. 96, III**, da CF/88, dada a presença, entre os acusados, de um juiz de direito, a competência, **de acordo com as circunstâncias do caso** e se assim se **demonstrar** e se **justificar**, será do **TJ** para o julgamento de todos (*vide* vários precedentes: HC 68.846-RJ — *RTJ* 157/563; HC 74.573-RJ — *DJU* de 30.04.1998; PET 760-DF — *RTJ* 155/722; HC 79.922-RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, 29.02.2000 etc.).

Esse entendimento de não se adotar a regra (técnica) do desmembramento foi sustentado, também, no **inquérito** do “**mensalão**” (Inq. 2.245), mantendo-se a investigação contra os denunciados no STF, mesmo não tendo alguns prerrogativa de foro. Vejamos:

“Questão de ordem. Inquérito. Desmembramento. Art. 80 do CPP.⁴³ Critério subjetivo afastado. Critério objetivo. **Inadequação ao caso concreto**. Manutenção integral do inquérito sob julgamento da Corte. Rejeitada a proposta de adoção do critério subjetivo para o desmembramento do inquérito, nos termos do art. 80 do CPP, resta o critério objetivo, que, por sua vez, é **desprovido de utilidade no caso concreto**, em face da **complexidade do feito**. Inquérito não desmembrado. Questão de ordem resolvida no sentido da **permanência**, sob a jurisdição do **STF**, de **todas** as pessoas denunciadas” (Inq. 2.245-QO-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.12.2006, Plenário, *DJ* de 09.11.2007).

Outrossim, no julgamento da correspondente **ação penal** (AP 470 — “**mensalão**”), novamente, o STF, em **02.08.2012**, manteve o entendimento, rejeitando a questão de ordem que retomava o pedido de desmembramento do feito (na medida em que existiam réus que não eram parlamentares; aliás, a grande maioria).⁴⁴

Dentre os vários argumentos utilizados pelos Ministros (no sentido do não desmembramento), podemos destacar:

■ **devido processo legal e duração razoável do processo:** a remessa dos autos a eventual outro juízo provocaria desarrazoada demora no julgamento e, diante da complexidade do feito, aumentaria o risco de se

caracterizar a *prescrição da pretensão punitiva*;

- **risco** de, admitido o desmembramento, serem prolatadas **decisões inconciliáveis** e **contraditórias**, especialmente nas hipóteses de crime de quadrilha e de coautoria;

- a situação particular do julgamento do “mensalão”, em razão da **complexidade da causa** e do **volume de informações** (38 réus, 234 volumes, 495 apensos, 50.199 páginas, o que se confirmou em razão da necessidade de 53 sessões de julgamento).

Ainda, o STF, **negando o desmembramento**, declarou não ser obrigatório o preenchimento do *princípio do duplo grau de jurisdição* nas causas de sua **competência originária**, prevalecendo a regra da CF/88 inclusive em relação a tratados internacionais de direitos humanos, no caso o Pacto de São José da Costa Rica, que destaca o referido princípio do duplo grau de jurisdição (cf. **RHC 79.785**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.03.2000, Plenário, *DJ* de 22.11.2002).

O tema da prerrogativa de foro e o seu desmembramento foi retomado no julgamento do Inq 3.515 AgR/SP e, de maneira bastante importante, o Min. Roberto Barroso propôs a tentativa de uma **roteirização** e **padronização** diante do reconhecimento de **oscilação** da Corte em definir um critério único para o enfrentamento do tema.

Observou o Min. Roberto Barroso que, nos processos mais antigos, o STF tendia a aplicar isoladamente o art. 80 do CPP, sugerindo uma opção pelo desmembramento por motivo de conveniência para a prestação jurisdicional.

Sem abandonar a regra do art. 80, observou que, nas últimas decisões, a Corte, como indicado nos casos por nós destacados acima, adotou a **regra do desmembramento** e a manutenção do julgamento conjunto apenas como excepcionalidade. Como disse o Min. Roberto Barroso, “nessa linha, o Ministro Ricardo Lewandowski, em suas manifestações mais recentes, tem sustentado que o desmembramento deve ocorrer a menos que ‘a conduta dos agentes esteja **imbricada** de tal modo que torne por demais complexo individualizar a participação de cada um dos envolvidos’. De forma ainda mais estrita, o

Ministro Marco Aurélio tem se pronunciado pela **necessidade taxativa de desmembramento**, mesmo nos casos de conexão ou continência, o que é coerente com o entendimento de S. Exa. quanto à improrrogabilidade das hipóteses de competência desta Corte, definidas na Constituição” (fls. 10 do voto).

No julgamento do Inq 2.288, que originou a AP 536, a **regra** foi também no sentido do **desmembramento**, diante do excessivo número de acusados e de apenas um (no caso, Senador da República) com prerrogativa de foro no STF.

Por todo o exposto, pode-se concluir no sentido da **regra geral do desmembramento**, devendo cada réu ser julgado pelo eventual tribunal competente no caso de ter prerrogativa de foro, ou ser julgado no primeiro grau de jurisdição, se não exercer nenhuma função que enseje esta ou aquela prerrogativa.

Como propôs o Min. Roberto Barroso na ementa de seu voto, “a menos que haja risco de prejuízo relevante para a apuração dos fatos investigados e/ou para a prestação jurisdicional, deve-se proceder ao **desmembramento** de investigação ou processo já instaurado a fim de **limitar** a atuação do Supremo Tribunal Federal aos detentores de foro por prerrogativa de função” (**Inq 3.515 AgR/SP**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.2.2014, *DJE* de 25.02.2014).

Entenderam os Ministros nos debates do julgamento do Inq 3.515 AgR/SP que a decisão sobre o desmembramento **independe de requerimento do Ministério Público** e deve ser tomada **o quanto antes, o mais precoce possível**.

O Min. Teori Zavascki, também reforçando a **regra para o desmembramento**, estabeleceu: “a competência do Supremo é restrita e só em **situações excepcionais**, justificáveis por razões objetivas, é que se instala a competência do Supremo”.

Nessas hipóteses de excepcionalidade, diante de **circunstâncias especiais** a serem apreciadas, demonstradas e justificadas em cada caso concreto, necessária será a observância da regra contida no art. 78, III, do CPP, que, como já se disse, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior

graduação, deliberando-se pelo julgamento conjunto de todos os corrêus (cf. *Inf. 673/STF*).

■ 10.4.15.5. *Distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na CF — Rcl 2.138-6-DF*

O Ministro Nelson Jobim, relator, no julgamento do mérito da *Rcl 2.138-6*, “... fazendo a distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na CF, quais sejam, o previsto no art. 37, § 4.º, e regulado pela Lei n. 8.429/92, e o regime de crime de responsabilidade fixado no art. 102, I, letra ‘c’, e disciplinado pela Lei n. 1.079/50, votou pela procedência do pedido formulado na reclamação por entender que os **agentes políticos**, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade, **não respondem por improbidade administrativa com base na Lei n. 8.429/92**, mas **apenas por crime de responsabilidade** em ação que somente pode ser proposta perante o STF nos termos do art. 102, I, ‘c’, da CF (...). Em síntese, o Min. Nelson Jobim proferiu voto no sentido de julgar procedente a reclamação para assentar a competência do STF e declarar extinto o processo em curso na 14.^a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que gerou a reclamação, no que foi acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Maurício Corrêa e Ilmar Galvão. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Carlos Velloso” (*Inf. 291/STF*, 20.11.2002).

Em 13.06.2007, o STF, por **6 x 5**, decidiu pela tese sustentada pelo Min. Jobim.

Hugo Nigro Mazzilli, no entanto, restringindo esse entendimento (e aqui a posição da doutrina é apenas para trazer outros elementos sobre a questão — devendo o ilustre leitor tomar cuidado nas provas preambulares e adotar a posição do STF), observa que “nas ações de improbidade fundadas na Lei n. 8.429/92, em que o pedido envolva **perda da função pública** ou **suspensão de direitos políticos**, se a autoridade requerida estiver entre aquelas para as quais haja forma própria de investidura e destituição prevista na Constituição, o foro

será o da ação por crime de responsabilidade”. Isso porque, “para as ações de improbidade fundadas na Lei n. 8.429/92, em que o pedido envolva apenas e tão somente a defesa do erário, a competência em primeiro grau de jurisdição será de **juízes singulares**, da mesma forma que já ocorre com as ações populares com o mesmo objeto”.

CUIDADO: o nosso ilustre leitor deve ficar atento ao julgamento da **PET 3.240 AgR** (*pendente*), na qual dois importantes temas estão sendo rediscutidos:

- **duplo regime:** em relação aos atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92 x Lei n. 1.079/50);

- **prerrogativa de foro:** restringe-se apenas às ações penais ou pode ser estendida também para as hipóteses de improbidade?

Revedo o posicionamento firmado na RCL 2.138, o único voto proferido até o fechamento desta edição foi o do Min. Teori Zavascki que preservou o entendimento da especialidade da Lei n. 1.079/50 **apenas** para o Presidente da República. Assim, os demais agentes políticos estariam sujeitos também às sanções previstas no art. 37, § 4.º, CF/88.

Ainda, evoluindo e modificando o entendimento da Corte, o voto do Min. Teori Zavascki sustenta a prerrogativa de foro **também para as ações de improbidade**. “Explicou que, embora as sanções aplicáveis aos atos de improbidade não tivessem natureza penal, haveria laços de identidade entre as duas espécies, seja quanto às funções (punitiva, pedagógica e intimidatória), seja quanto ao conteúdo. Com efeito, não haveria diferença entre a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos ou a imposição de multa pecuniária, quando decorrente de ilícito penal e de ilícito administrativo. Nos dois casos, as consequências práticas em relação ao condenado seriam idênticas. A rigor, a única distinção se situaria em plano puramente jurídico, relacionado com os efeitos da condenação em face de futuras infrações, porquanto a condenação criminal produziria as consequências próprias do antecedente e da perda da primariedade, que poderiam redundar em futuro agravamento de penas ou, indiretamente, em aplicação de pena privativa de liberdade” (*Inf. 768/STF — em 19.11.2014, o Min. Roberto Barroso pediu vista dos autos*).

■ 10.4.15.6. Responsabilidade fiscal e as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas — LC n. 101/2000 e Lei n. 10.028/2000

O tema da **responsabilidade fiscal** vem sendo constantemente discutido, sobretudo diante das regras trazidas pela **LC n. 101/2000** (nesse particular, acompanhar o julgamento da **ADI 2.238/STF**, já tendo sido **suspensa a eficácia** de alguns dispositivos da referida lei, como os arts. 9.º, § 3.º; 12, § 2.º; a expressão “quanto pela redução dos valores a eles atribuídos” do § 1.º do art. 23 e, integralmente, o seu § 2.º) (**matéria pendente**), bem como as alterações implementadas pela **LC n. 148/2014**.

Não pretendemos, aqui, discutir a referida lei, na medida em que fugiria do propósito deste trabalho.

Cabe, porém, esquematizar algumas regras. A importância da lei em comento é indiscutível, uma vez que estabelece **normas de finanças públicas**, voltadas para a **responsabilidade na gestão fiscal**, além de outras providências, a serem observadas pela União, Estados, DF e Municípios.

De acordo com a lei, no que se refere à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos o **Poder Executivo**, o **Poder Legislativo**, neste abrangidos os **Tribunais de Contas**, o **Poder Judiciário** e o **Ministério Público**, bem como as respectivas **administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes** (art. 1.º, § 3.º, I, “a” e “b”).

O maior objetivo do legislador, ao que parece, foi **equacionar os gastos públicos**, vinculando-os à **receita**. O administrador obriga-se, portanto, a instrumentalizar verdadeiro planejamento administrativo, contábil e patrimonial de sua gestão fiscal, de maneira transparente e responsável, perspectiva ampliada pela **LC n. 131, de 27.05.2009**, que acrescenta dispositivos à LC n. 101/2000, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesses termos é que o art. 1.º, § 1.º, da lei determina que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a **ação planejada** e **transparente**, em que se

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de **metas** de resultados entre **receitas e despesas** e a **obediência a limites e condições** no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

De modo geral, a lei dispõe sobre: **a)** planejamento público; **b)** receita pública; **c)** despesas públicas; **d)** transferências voluntárias; **e)** destinação de recursos públicos para o setor privado; **f)** dívida e endividamento; **g)** gestão patrimonial; **h)** transparência, controle e fiscalização.

Em suas disposições finais e transitórias (art. 73), o legislador determinou que qualquer infração aos dispositivos fixados na lei em análise será punida segundo o Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente, em especial diante das novas regras trazidas pela **Lei n. 10.028/2000**, já comentadas ao longo desta obra.

Resta, pois, destacar o art. 5.º da Lei n. 10.028/2000, que caracterizou atos constitutivos de **infrações administrativas contra as leis de finanças públicas** (e a LC n. 101/2000 é exemplo daquela), a serem processadas e julgadas pelo **Tribunal de Contas** a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. Assim, constitui **infração administrativa**, punida com multa de **30%** dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, cujo pagamento será de sua responsabilidade pessoal:

- deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
- propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da lei;
- deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

■ deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.

A questão dos **gastos públicos** deve receber redobrada atenção, especialmente com as despesas realizadas para os jogos da **Copa do Mundo de 2014**, bem como para as **Olimpíadas de 2016** (cf., por exemplo, discussões na AC 2.684, ACO 1.674 etc. — **matéria pendente**).

■ 10.5. QUESTÕES

1. (OAB/SP/107.º) É competência privativa do Presidente da República, sem possibilidade de delegação:

- a) nomear os diretores do Banco Central;
- b) prover cargos públicos federais;
- c) conceder indulto;
- d) dispor sobre moeda e seus limites de emissão.

2. (Magistratura/SP/167.º) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:[45](#)

- a) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o Ministro-Chefe do estado-Maior das Forças Armadas;
- b) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do STF;
- c) o Presidente do STF, o do Senado e o da Câmara;
- d) o Presidente da Câmara, o do Senado e do STF.

3. (Oficial da Defensoria Pública do Estado de SP/FCC/2010) Em caso de vacância do cargo de Governador do Estado de São Paulo e diante do impedimento do Vice-Governador, será chamado para governar o Presidente

- a) do Tribunal de Justiça.
- b) do Tribunal de Contas do Estado.
- c) da Assembleia Legislativa.
- d) da Câmara de Vereadores.

e) do Congresso Nacional.

4. (Nossa) Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são julgados:

- a) pelo Senado Federal em crime de responsabilidade e pelo TRF de Brasília por crime comum;
- b) sempre pelo STF;
- c) pelo STF em caso de crime comum e de responsabilidade, mas, no caso de crime de responsabilidade conexo com o praticado pelo Presidente da República, a competência será do Senado Federal;
- d) pelo STF em crime comum e pelo Senado Federal em crime de responsabilidade.

5. (Magistratura/173.º) Ao Superior Tribunal de Justiça compete julgar:

- a) os Governadores dos Estados, nos crimes de responsabilidade;
- b) os Desembargadores, nos crimes comuns e de responsabilidade;
- c) os membros dos Tribunais de Contas, apenas nos crimes comuns;
- d) os membros dos Ministérios Públicos que oficiem perante tribunais.

6. (MP/SP 2006) Assinale a alternativa correta. É competência privativa do Presidente da República:

- a) Nomear e exonerar Ministros de Estado *ad referendum* do Senado Federal.
- b) Sancionar, promulgar e fazer publicar leis e emendas constitucionais, bem como expedir documentos e regulamentos para sua fiel execução.
- c) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, bem como celebrar tratados e convenções e atos internacionais desde que previamente aprovados pelo Congresso Nacional, com antecedência mínima de 30 dias.
- d) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, podendo delegar tal atribuição ao Procurador-Geral da República.
- e) Editar medidas provisórias com força de lei, podendo delegar tal atribuição a Ministro de Estado, observados os limites traçados na respectiva delegação.

7. (Procurador da Assembleia Legislativa de SP/FCC/2010) Com relação ao Poder Executivo, é competência privativa do Presidente da República, além de outras:

- a) manter relações com Estados estrangeiros mediante prévia análise dos seus representantes diplomáticos, competindo-lhe, em regra, investigar previamente suas origens e intenções com o fim de garantir a segurança nacional.

- b) remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias.
- c) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, independentemente do referendo do Congresso Nacional.
- d) exercer o comando supremo das Forças Armadas e, após aprovação pelo Senado Federal, promover e nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e os oficiais-generais para os cargos que lhes são privativos.
- e) nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei.

8. (TJ/DF — 2007) Sobre os Conselhos da República e de Defesa Nacional, tal como disciplinados no texto da Constituição da República de 1988, é correto afirmar:

- a) O líder na minoria no Senado Federal participa do Conselho da República, mas não participa do Conselho de Defesa Nacional;
- b) Compete ao Conselho da República estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático;
- c) Compete ao Conselho de Defesa Nacional pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
- d) O Ministro do Planejamento não é membro nato do Conselho de Defesa Nacional.

9. (Acadepol — 2007-PR) São atribuições e responsabilidades do Presidente da República, EXCETO:

- a) declarar guerra no caso de agressão estrangeira, independentemente de autorização ou referendo do Congresso Nacional, se a situação for de urgência e comprometer a segurança nacional.
- b) iniciar o processo legislativo.
- c) nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e os Ministros do Tribunal de Contas da União.
- d) nomear e exonerar os Ministros de Estado.
- e) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

10. (Notário SC/TJ SC/2008) Assinale a alternativa correta:

- a) O Presidente e o Vice-Presidente da República não podem, sem prévia licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País, sob pena de perda do cargo.
- b) Conforme o Supremo Tribunal Federal, a sanção do Chefe do Poder Executivo afasta a inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa.
- c) Sempre que ocorrer a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente será convocada eleição para a escolha dos sucessores.
- d) O Presidente da República poderá editar medidas provisórias sobre qualquer matéria desde que atendidos os pressupostos da relevância e da urgência.
- e) Nos afastamentos do Presidente e do Vice-Presidente da República assume a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados.

11. (Notário SP/2008) Constituem requisitos para a nomeação ao cargo de Ministro de Estado:

- a) a nacionalidade brasileira e permanecer domiciliado no Brasil.
- b) a nacionalidade brasileira e ter idade superior a vinte e um anos.
- c) ter idade superior a vinte e um anos e permanecer domiciliado no Brasil.
- d) ser brasileiro nato e ter idade superior a vinte e um anos.

12. (Exame da OAB Unificado 2010.2 — FGV) Em relação aos Ministros de Estado, a Constituição do Brasil estabelece que:

- a) como delegatários do Presidente da República, podem, desde que autorizados, extinguir cargos públicos.
- b) podem expedir instruções para a execução de leis e editarem medidas provisórias.
- c) somente os brasileiros natos poderão exercer a função.
- d) respondem, qualquer que seja a infração cometida, perante o Superior Tribunal de Justiça.

13. (OAB-CESPE/UnB — 2008) No que concerne à disciplina constitucional relativa ao Poder Executivo, assinale a opção correta.

- a) Se, antes do segundo turno da votação, houver morte, desistência ou impedimento de candidato à chefia do Poder Executivo federal, deverá ser convocado, entre os remanescentes, o de maior votação.
- b) Será considerado eleito presidente da República, em primeiro turno, o candidato que

obtiver a maioria absoluta de votos, computados os votos em branco e os nulos.

- c) Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse presidencial, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, deverá ser convocado, para assumir o cargo, o segundo mais votado no pleito eleitoral.
- d) Em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República ocorrida nos últimos dois anos do mandato presidencial, deverá ser realizada eleição direta após 90 dias contados da abertura da última vaga.

14. (Diplomata CESPE/UnB — 2009) O Conselho da República, previsto como órgão superior de consulta do Presidente da República, nos termos da Constituição Federal, cuida de relevantes assuntos da vida do Estado. Acerca da atuação desse Conselho, assinale a opção correta:

- a) O Ministro de Estado das Relações Exteriores dele participa como membro nato e, portanto, está dispensado de convocação para as reuniões.
- b) O Conselho da República decide, em última instância, sobre questões relevantes para a estabilidade e a continuidade das instituições democráticas.
- c) Algumas atribuições do Conselho da República são compartilhadas com o Conselho de Defesa Nacional, com o qual, no entanto, o primeiro não se confunde.
- d) O Conselho da República é composto por membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e da sociedade civil.
- e) Havendo composição plena, o Conselho da República atua de forma conjunta com o Conselho Nacional de Justiça.

15. (OAB 138 CESPE/UnB — 2009) No tocante à responsabilização do presidente da República, assinale a opção correta.

- a) Tratando-se de crime de responsabilidade, a decisão proferida pelo Senado Federal pode ser alterada pelo STF.
- b) São alternativas as sanções de perda do cargo de presidente e de inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública.
- c) Na CF, é assegurada ao presidente da República a prerrogativa de somente ser processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados.
- d) Compete ao STF processar e julgar originariamente o presidente da República nas infrações penais comuns e nas ações populares.

16. (Técnico Judiciário — Área Administrativa/TRE-BA/CESPE/UnB — 2010) Julgue o item abaixo, a respeito do Poder Executivo.

Na eleição do presidente e do vice-presidente da República, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, deve ser feita nova eleição, concorrendo os dois candidatos mais votados. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer a morte de candidato, deverão ser convocadas novas eleições.

17. (50.º MP Minas Gerais — 2010) Quanto ao Poder Executivo da União, é CORRETO afirmar que:

- a) é exercido pelo Presidente da República e pelos Ministros de Estado.
- b) é exercido pelo Presidente da República e pelos congressistas escolhidos por aquele.
- c) é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
- d) é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Congresso Nacional.

18. (Procurador Jurídico da USP/FUVEST — 2011) Segundo a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, as normas constantes da Constituição Estadual que disciplinam a eleição do novo titular do Poder Executivo estadual, em face de vacância nos cargos de Governador e Vice-Governador:

- a) incorrem em vício de inconstitucionalidade, pois cumpre observar, tanto quanto possível, o padrão da linha sucessória definida para o âmbito federal, cabendo ao Presidente da Assembleia Legislativa ou ao Presidente do Tribunal de Justiça o exercício do cargo pelo restante do mandato.
- b) não estão sujeitas ao princípio da simetria, cabendo-lhes definir regime próprio, ainda que diverso da disciplina constante da Constituição Federal sobre a vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República.
- c) cabem ser impugnadas diretamente em sede de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do respectivo Estado em razão de contrariedade com a Constituição Federal.
- d) cabem ser definidas automaticamente pelo poder constituinte decorrente, a exemplo das normas que disciplinam o processo e o julgamento do Governador e do Vice-Governador por crime de responsabilidade.
- e) incorrem em vício de inconstitucionalidade, pois direito eleitoral constitui matéria sujeita à competência legislativa privativa da União.

19. (Procurador — TCE-SP — FCC/2011) Considera-se função atípica do Poder

Executivo, sob a ótica do princípio da separação de poderes, a previsão constitucional segundo a qual compete ao Presidente da República:

- a) vetar e sancionar projetos de lei.
- b) suspender a eficácia de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
- c) editar decretos e regulamentos para a execução de leis.
- d) nomear Ministros do Supremo Tribunal Federal, após arguição pelo Congresso Nacional.
- e) editar leis delegadas e medidas provisórias.

20. (Técnico de Controle Externo — TCE-AP — FCC/2012) O Vice-Presidente da República:

- a) deve ser brasileiro nato ou naturalizado.
- b) exerce competências taxativamente definidas na Constituição e em leis ordinárias.
- c) substitui o Presidente, no caso de impedimento, e sucede-lhe, no caso de vacância.
- d) poderá ser julgado, por crime de responsabilidade, pelo Congresso Nacional.
- e) deve ter a idade mínima de trinta anos como condição de sua elegibilidade.

21. (Técnico de Controle Externo — TCE-AP — FCC/2012) Se o Presidente da República atira contra seu próprio primo e comete um crime de homicídio, na vigência de seu mandato, motivado, apenas, por violento ciúme em relação à esposa,

- a) não poderá ser responsabilizado pelo ato enquanto durar seu mandato.
- b) será processado e julgado, na vigência de seu mandato, pelo Supremo Tribunal Federal.
- c) será processado e julgado, na vigência de seu mandato, pelo Senado Federal, e, caso seja considerado culpado, sofrerá a pena de *impeachment*.
- d) será submetido a um primeiro julgamento perante o Congresso Nacional, o qual decidirá sobre a manutenção da decretação da prisão preventiva.
- e) poderá ficar afastado do cargo, por decisão do Senado Federal, até que se ultime o julgamento no Supremo Tribunal Federal.

22. (Analista Judiciário — Execução de Mandados — TRT11 — FCC/2012) É lícito ao Presidente da República delegar ao Ministro de Estado a atribuição de:

- a) exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos.

- b) manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos e celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- c) dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
- d) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei.
- e) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional, conferir condecorações e distinções honoríficas e enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

23. (ABIN — Agente de Inteligência — CESPE/UnB/2008) Acerca do Poder Executivo, julgue o item seguinte:

O Presidente da República pode delegar aos Ministros de Estado, conforme determinação constitucional, a competência de prover cargos públicos, a qual se estende também à possibilidade de desprovemento, ou seja, de demissão de servidores públicos.

24. (Magistratura — TRF5 — CESPE/UnB/2009) Acerca do Poder Executivo, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, assinale a opção correta:

- a) Todos os membros do Conselho da República, órgão de consulta da Presidência, são escolhidos pelo Presidente da República.
- b) Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar a respeito das questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
- c) Para que o Presidente da República seja julgado pelo STF por crimes comuns, é necessária a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados, por força da qual fica ele suspenso das suas funções.
- d) Não se submete ao controle concentrado de constitucionalidade, conforme entendimento do STF, o decreto que, dando execução a lei inconstitucional, cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações.
- e) Conforme entendimento do STF, o Presidente da República pode delegar aos Ministros

de Estado, por meio de decreto, a atribuição de demitir, no âmbito das suas respectivas pastas, servidores públicos federais.

25. (Técnico Judiciário — Segurança Judiciária — TRE-BA — CESPE/UnB/2010) Julgue o item a seguir, acerca da organização dos poderes:

Para que seja instaurado processo contra Ministro de Estado, é necessária autorização do Senado Federal.

26. (Técnico Judiciário — TRE/MS — Área Administrativa — CESPE/UnB/2013) Em relação ao Poder Executivo, assinale a opção correta:

- a) Para ocupar o cargo de Ministro de Estado, o cidadão deve ter, no mínimo, trinta anos de idade e estar no exercício de seus direitos políticos.
- b) Não cabe aos Ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República.
- c) O Presidente da República tem autonomia para vetar artigo de projeto de lei por razões de inconstitucionalidade.
- d) A CF autoriza a criação ou a extinção de órgãos públicos por meio de decreto presidencial.
- e) A nomeação do Procurador-geral da República pelo Presidente da República independe de prévia aprovação do Senado Federal.

27. (Analista Técnico/MS/Administrativo — CESPE/UnB/2013) No que diz respeito aos poderes do Estado e às funções essenciais da justiça, julgue o próximo item.

A acumulação das funções de chefe de Estado e de chefe de governo pelo presidente da República é uma das características do sistema presidencialista de governo adotado pela República Federativa do Brasil.

28. (Analista em Geociências — CPRM — CESPE/UnB/2013) Julgue o item a seguir, relativo aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, e suas atribuições constitucionais são indelegáveis.

29. (Analista Legislativo — Câmara dos Deputados — Consultor Legislativo Área VIII — CESPE/UnB/2014) A respeito da organização do Estado e dos poderes, julgue o próximo item:

Se uma constituição estadual caracterizar como crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado convocado pela assembleia legislativa para dar explicações sobre fato relevante, essa norma será constitucional, uma vez que a CF assim dispõe em relação aos ministros de Estado.

■ GABARITO ■

1. “a”. Art. 84, XIV, combinado com o art. 84, parágrafo único. Isso porque as alternativas “b” e “c” poderão ser delegadas aos Ministros de Estado, ao PGR ou ao AGU, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. No tocante à competência para dispor sobre moeda e seus limites, a atribuição, de acordo com o art. 48, XIV, é do Congresso Nacional (<i>vide</i> , ainda, os arts. 21, VII, e 164 da CF).
2. “d”. Cf. art. 80 da CF/88.
3. “c”. Cf. art. 80 da CF/88, por simetria. <i>Vide</i> parte teórica.
4. “c”. Art. 52, I, combinado com o art. 102, I, “c”, na redação determinada pela EC n. 23, de 02.09.1999.
5. “b”. Art. 105, I, “a”. Governador de Estado, no caso do Estado de São Paulo, de acordo com o art. 49, § 1.º, da CE, é julgado pelo Tribunal Especial, conforme visto na parte teórica, com suas advertências. Os membros dos Tribunais de Contas (Estadual, Distrital e Municipal) são julgados pelo STJ não só nos crimes comuns, como também nos de responsabilidade (art. 105, I, “a”). Já os membros do TCU são julgados pelo STF, nos crimes comuns e de responsabilidade. Por fim, os membros do MP que oficiem perante tribunais: a) membros do MP da União — crime comum e de responsabilidade — STJ, art. 105, I, “a”; b) MPEstadual — crime comum e de responsabilidade — TJ, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Ao que parece, o erro da alternativa “d” está no fato de o examinador não ter especificado quais membros do MP, já que a competência é do STJ somente em relação àqueles que oficiem perante tribunais, mas que sejam membros da carreira federal, ou seja, o MP da União.
6. “d”. Art. 84, XII, c/c o parágrafo único da CF/88.
7. “b”. Art. 84, XI, da CF/88. Trata-se de questão que exigia o conhecimento da literalidade dos

incisos do art. 84.
8. “a”.
9. “a”. Art. 84, XIX.
10. “e”. Art. 80 da CF/88.
11. “b”. Art. 87 da CF/88.
12. “a”. Cf. parágrafo único do art. 84.
13. “a”.
14. “c”. Por exemplo, art. 90, I, e art. 91, § 1.º, II. A <i>letra “a”</i> está errada nos termos do art. 91, VI (Conselho de Defesa Nacional). A <i>letra “b”</i> está errada porque o Conselho da República não decide, mas pronuncia-se, oferecendo parecer não vinculativo. A <i>letra “d”</i> está errada porque, na composição do Conselho (art. 89), não constam membros do Judiciário. A <i>letra “e”</i> está errada porque não há atuação conjunta com o CNJ.
15. “c”.
16. “errado”. Art. 77, § 4.º.
17. “c”. Art. 76.
18. “b”.
19. “e”.
20. “c”.
21. “a”.
22. “c”. Cf. art. 84, parágrafo único, c/c o art. 84, VI, “a” e “b”.
23. “certo”, cf. parte teórica, <i>item 10.4.2.2.</i>
24. “e”, cf. parte teórica, <i>item 10.4.2.2.</i> A <i>letra “a”</i> está errada em razão da origem dos integrantes do Conselho. Por exemplo, o Vice-Presidente da República é eleito pelo povo. A

atribuição indicada na <i>letra “b”</i> é do Conselho da República (art. 90, II). A <i>letra “c”</i> está errada por violar o art. 86, § 1.º, I, na medida em que o Presidente da República ficará suspenso de suas funções, nas infrações penais comuns (hipótese da alternativa), se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, e não em razão do juízo de admissibilidade pela Câmara. A <i>letra “d”</i>, diferentemente do afirmado, viola entendimento firme no STF, mostrando a importância de se conhecer a jurisprudência da Corte para provas elaboradas pelo CESPE/UnB e outras tantas bancas. 46
25. “errado”. Conforme vimos na parte teórica, o STF interpretou que a <i>condição de procedibilidade ou admissibilidade do processo</i> (por crime comum ou por crime de responsabilidade) só será exigida na hipótese de crime de responsabilidade praticado por Ministro de Estado conexo com aquele praticado pelo Presidente da República e, no caso, será atribuição da Câmara dos Deputados (art. 51, I), e não do Senado Federal.
26. “c”.
27. “certo”.
28. “errado”. Cf. 84, parágrafo único.
29. “errado”. Conforme vimos, a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é da União (S. 722/STF).

PODER JUDICIÁRIO

■ 11.1. FUNÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO

Como já pudemos observar, o Poder Judiciário tem por **função típica** a **jurisdicional**, inerente à sua natureza. Exerce, ainda, **funções atípicas**, de **natureza executivo-administrativa** (organização de suas secretarias — art. 96, I, “b”; concessão de licença e férias a seus membros, juízes e servidores imediatamente vinculados — art. 96, I, “f”), bem como **funções atípicas** de **natureza legislativa** (elaboração do regimento interno — art. 96, I, “a”).

Podemos conceituar a **jurisdição** como “uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre por meio do processo, seja expressando imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da execução forçada)”.¹

■ 11.2. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO

Apenas para ilustrar o tema (devendo o estudo mais aprofundado ser buscado nos compêndios de processo e sua teoria geral), trazemos em pauta três

características básicas da jurisdição, quais sejam: **lide**, **inércia** e **definitividade**.

Na jurisdição contenciosa, por regra, existirá uma **pretensão resistida**, insatisfeita. A partir do momento que essa pretensão não é pacificamente resolvida pelo suposto causador da insatisfação, quem entender-se lesado poderá “bater” às portas do judiciário, que, substituindo a vontade das partes, dirimirá o conflito, afastando a resistência e pacificando com justiça. [2](#)

A segunda característica transparece na máxima *nemo iudex sine actore*; *ne procedat iudex ex officio*, ou seja, o Judiciário só se manifesta mediante **provocação** (vide arts. 2.º do CPC/73 — com correspondência no art. 2.º do CPC/2015 — e 24 do CPP). [3](#)

Defendemos, contudo, na sociedade moderna, o aumento dos poderes instrutórios do juiz na condução do processo. Isso não significa, segundo já expusemos, [4](#) o exercício de “... atividade jurisdicional fora dos limites da lei, tomada em sua acepção ampla. A **legalidade** deverá ser sempre observada, podendo o magistrado avançar até os limites tolerados pelo ordenamento jurídico, desde que mantenha inatingível a integridade do *due process of law*”. [5](#)

Por fim, a **definitividade**, na medida em que as decisões jurisdicionais transitam em julgado e, acobertadas pela coisa julgada formal e material, após o prazo para a propositura da ação rescisória, não mais poderão ser alteradas. Ao contrário de alguns países da Europa, no Brasil toda decisão administrativa poderá ser reapreciada pelo Judiciário, não tendo sido conferido ao contencioso administrativo o poder de proferir decisões com força de coisa julgada definitiva. [6](#)

Diante do exposto, portanto, conclui-se que a jurisdição no Brasil é **una** (ou seja, a definitividade só é dada pelo judiciário) e **indivisível**, exercida pelo Judiciário nacionalmente (um só poder, materializado por diversos órgãos, federais e estaduais).

■ 11.3. REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO — EC N. 45/2004 [7](#)

■ 11.3.1. Histórico de sua tramitação

Antes de iniciarmos a análise das regras específicas sobre o Poder Judiciário convém lembrar a importante aprovação da **Reforma do Poder Judiciário**.

Conforme é de conhecimento de todos, no dia **17.11.2004**, finalmente, após 13 anos de tramitação, foi aprovada a **EC n. 45**.

Na Câmara dos Deputados, apresentada pelo Deputado Hélio Bicudo em 26.03.1992, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) recebeu o n. 96/92. Após vários anos, tendo como última relatora a Deputada Zulaiê Cobra, a referida PEC, aprovada em dois turnos, foi encaminhada para o SF, onde tomou o n. **29/2000**, tendo como primeiro relator o Senador Bernardo Cabral, que emitiu importantes pareceres, ns. 538 e 1.035/2002, ambos aprovados pela CCJC.

Naquele mesmo ano, contudo, a legislatura se encerrou sem a apreciação da matéria em segundo turno, apesar do enorme esforço do Senador Bernardo Cabral, que não foi reeleito. Iniciada a nova legislatura, além de expressivo número de emendas apresentadas no primeiro turno durante a legislatura anterior, a grande renovação da Casa, mais de 50% de sua composição, fez com que o Presidente do SF, José Sarney, com o aval absoluto do plenário, determinasse o retorno da matéria à CCJC para novo parecer, tendo sido designado, então, em 26.06.2003, o Senador José Jorge como o novo relator da Reforma do Judiciário.

No Senado, a partir do ano 2000, 17 PECs sobre o Judiciário tramitaram em conjunto, tendo sido realizadas 14 audiências públicas com a participação de Ministros do STF, Tribunais Superiores, OAB, MP, institutos, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) etc. O SF, diante dessa multiplicidade de projetos, transformou as 17 PECs em outras 4, nos termos do **Parecer n. 451, de 2004-CCJ** (*DSF* de 08.05.2004, p. 12728-12912), e Emenda n. 240 da CCJC:

- a de n. 29/2000 foi aprovada, transformando-se na **EC n. 45/2004**, promulgada em 08.12.2004 e publicada em 31.12.2004;

■ uma segunda, desmembrando-se da anterior (e por isso denominada *PEC Paralela da Reforma do Poder Judiciário*), levou o n. 29-A/2000, também aprovada em dois turnos no SF. Na medida em que modificou a redação de artigos da originária PEC n. 96/92 da CD, teve de retornar àquela Casa em prestígio ao **princípio do bicameralismo**. Na CD foi reapresentada em **10.01.2005**, tomando o n. **358/2005** para ser discutida e votada em dois turnos e buscando alterar os seguintes dispositivos da CF/88: arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105, 107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A e 134. Acrescenta, ainda, os arts. 97-A, 105-A, 111-B e 116-A e dá outras providências. Dentre tantas novidades, a referida **PEC n. 29-A/00-SF (358/05-CD)**: transfere da União para o DF a defensoria do DF, tornando-a autônoma (nesse sentido, destacamos a **EC n. 69/2012**, que alterou os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal); dá autonomia também à Defensoria Pública da União (nesses termos, cf. o art. 134, § 3.º, introduzido pela **EC n. 74/2013**);⁸ restringe a competência dos TJs para o julgamento de Prefeitos; altera o art. 93; inclui a necessidade de permanência de três anos no cargo para que o magistrado tenha direito à vitaliciedade na função; proíbe a prática de nepotismo nos Tribunais e Juízos; modifica a competência da Justiça Trabalhista, novamente; altera a composição do STM e regras sobre o MP; amplia as competências do STF e STJ; institui a “súmula impeditiva” de recursos, a ser editada pelo STJ e TST; trata da conciliação, mediação e arbitragem etc.;⁹

■ uma terceira PEC foi apresentada ao próprio SF, a de n. **26/04-SF**, que, alterando o art. 100 da CF/88, permitia o parcelamento de precatórios (chamados de **títulos sentenciais**) em até 60 parcelas. Nos termos do art. 332 do *RISF*, referida PEC foi **arquivada** ao final da 53.ª *Legislatura* (período de 2007 a 2010), já que não apreciada. De toda forma, sobre a matéria, mencionamos a aprovação da **EC n. 62, de 09.12.2009** (PECs ns. 12 e 12-A/2006-SF e PEC n. 351/2009-CD), que altera profundamente o sistema dos precatórios e é por nós comentada no *item 11.12* deste estudo;

■ nessa mesma situação de **arquivamento**, encontra-se uma quarta PEC,

de n. **27/04-SF**, que autorizava a lei a instituir juizados de instrução criminal para as infrações penais nela definidas.

■ 11.3.2. Principais alterações

Apresentamos abaixo 28 principais novidades trazidas pela Reforma do Judiciário (**EC n. 45/2004**), cujo desenvolvimento é abordado ao longo do estudo:

- 1) a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (**art. 5.º, LXXVIII, e art. 7.º da EC n. 45/2004**). Como bem exposto na *Exposição de Motivos do CPC/2015* (Lei n. 13.105/2015), “a ausência de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de Justiça”;
- 2) a previsão de real cumprimento do princípio do acesso à ordem jurídica justa, estabelecendo-se a Justiça itinerante e a sua descentralização, assim como a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública Estadual (**arts. 107, §§ 2.º e 3.º; 115, §§ 1.º e 2.º; 125, §§ 6.º e 7.º; 134, § 2.º; 168; e art. 7.º da EC n. 45/2004**);
- 3) a possibilidade de se criarem varas especializadas para a solução das questões agrárias. Nessa linha de especialização em prol da efetividade temos sugerido, também, varas especializadas para a área do consumidor, ambiental, coletiva etc. (art. 126, *caput*);
- 4) a “constitucionalização” dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde que aprovados pelo *quorum* qualificado das emendas constitucionais (**art. 5.º, § 3.º**);
- 5) a submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI) a cuja criação tenha manifestado adesão (**art. 5.º, § 4.º**);
- 6) a federalização de crimes contra direitos humanos, por exemplo, a tortura e o homicídio praticados por grupos de extermínio, mediante incidente suscitado pelo PGR no STJ, objetivando o deslocamento da competência

para a Justiça Federal. Busca-se, acima de tudo, adequar o funcionamento do Judiciário brasileiro ao sistema de proteção internacional dos direitos humanos (art. 109, V-A, e § 5.º);

7) a criação do *Conselho Nacional de Justiça*, que passa a ser Órgão do Poder Judiciário, com sede na Capital Federal. Ampliação de hipótese de *impeachment*, por crime de responsabilidade, a ser apurada pelo Senado Federal, abarcando todos os membros do CNJ (e do CNMP). Criação de ouvidorias para o recebimento de reclamações (arts. 52, II; 92, I-A, e § 1.º; 102, I, “r”; 103-B; e art. 5.º da EC n. 45/2004);

8) a previsão de controle do MP por intermédio do *Conselho Nacional do Ministério Público*, assim como a criação de ouvidorias para o recebimento de reclamações (arts. 52, II; 102, I, “r”; 130-A; e art. 5.º da EC n. 45/2004);

9) a ampliação de algumas regras mínimas a serem observadas na elaboração do *Estatuto da Magistratura*, todas no sentido de dar maior produtividade e transparência à prestação jurisdicional, na busca da efetividade do processo, destacando-se: a) previsão da exigência de três anos de atividade jurídica para o bacharel em Direito como requisito para o ingresso na carreira da Magistratura (quarentena de entrada); b) aferição do merecimento para a promoção conforme o desempenho, levando em conta critérios objetivos de produtividade; c) maior garantia ao magistrado, já que a recusa da promoção por antiguidade somente poderá implementar-se pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do Tribunal a que ele estiver vinculado, conforme procedimento próprio e assegurada a ampla defesa; d) impossibilidade de promoção do magistrado que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; e) previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo *etapa obrigatória do processo de vitaliciamento*; f) o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da *maioria absoluta* (e não mais 2/3) do respectivo tribunal ou do

Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; **g)** na hipótese de processo que tramite sob “segredo de justiça”, existindo colisão de dois grandes direitos fundamentais, quais sejam, a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo e o interesse público à informação, parecer o constituinte reformador dado preferência a este último; **h)** previsão de serem as decisões administrativas dos tribunais tomadas em *sessão pública*; **i)** modificação da sistemática de preenchimento das vagas dos integrantes do Órgão Especial dos Tribunais, sendo metade por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno; **j)** o fim das férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, tornando a atividade jurisdicional *ininterrupta*; **k)** previsão de número de juízes compatíveis com a população; **l)** possibilidade de os servidores receberem delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; **m)** distribuição imediata dos processos em todos os graus de jurisdição (**art. 93**);

10) a ampliação da garantia de imparcialidade dos órgãos jurisdicionais por meio das seguintes proibições: **a)** vedação aos juízes de receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; **b)** instituição da denominada *quarentena de saída*, proibindo membros da magistratura de exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram por aposentadoria ou exoneração pelo prazo de 3 anos. A *quarentena* também se aplica aos membros do MP (**arts. 95, parágrafo único, IV e V, e 128, § 6.º**);

11) a previsão de que as custas e emolumentos sejam destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça, fortalecendo-a, portanto (**art. 98, § 2.º**);

12) a regulação do procedimento de encaminhamento da proposta orçamentária do Judiciário e solução em caso de inércia. Proibição de realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais (**art. 99, §§ 3.º, 4.º e 5.º**);

13) a extinção dos Tribunais de Alçada, passando os seus membros a integrar os TJs dos respectivos Estados e uniformizando, assim, a nossa Justiça (**art. 4.º da EC n. 45/2004**);

14) a transferência de competência do STF para o STJ no tocante à homologação de sentenças estrangeiras e à concessão de *exequatur* às cartas rogatórias (**art. 102, I, “h” (revogada); 105, I, “i”, e art. 9.º da EC n. 45/2004**);

15) a ampliação da competência do STF para o julgamento de recurso extraordinário quando se *julgar válida lei local contestada em face de lei federal*. Muito se questionou sobre essa previsão. Observa-se que está **correta**, uma vez que, no fundo, quando se questiona a aplicação de lei, acima de tudo, tem-se conflito de constitucionalidade, pois é a CF que fixa as regras sobre competência legislativa federativa. Por outro lado, quando se questiona a validade de ato de governo local em face de lei federal, acima de tudo, estamos diante de questão de legalidade a ser enfrentada pelo STJ, como mantido na reforma (**arts. 102, III, “d”, e 105, III, “b”**);

16) a criação do requisito da *repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso* para o conhecimento do recurso extraordinário. Essa importante regra vai evitar que o STF julgue brigas particulares de vizinhos como algumas discussões sobre “assassinato” de papagaio ou “furto” de galinha já examinadas pela mais alta Corte (**art. 102, § 3.º**);

17) a adequação da Constituição, no tocante ao controle de constitucionalidade, ao entendimento jurisprudencial já pacificado no STF, constitucionalizando o efeito dúplice ou ambivalente da ADI e da ADC, assim como o seu efeito vinculante. Ampliação da legitimação para agir. Agora os legitimados da ADC são os mesmos da ADI (e não mais somente os 4 que figuravam no art. 103, § 4.º, *revogado*). Apenas para se adequar ao entendimento do STF e à regra do art. 2.º, IV e V, da Lei n. 9.868/99, fixou-se, expressamente, a legitimação da Câmara Legislativa e do Governador do DF para a propositura de ADI e agora de ADC (**arts. 102, § 2.º; 103, IV e V**;

revogação do § 4.º do art. 103; e art. 9.º da EC n. 45/2004);¹⁰

18) a ampliação da hipótese de intervenção federal dependendo de provimento de representação do Procurador-Geral da República para, além da já existente ADI Interventiva (art. 36, III, c/c o art. 34, VII), agora, também, objetivando *prover a execução de lei federal* (pressupondo ter havido a sua recusa). A competência, que era do STJ, passa a ser do **STF (art. 34, VI, primeira parte, c/c o art. 36, III; revogação do art. 36, IV; e o art. 9.º da EC n. 45/2004)**;

19) a criação da Súmula Vinculante do STF (**art. 103-A e art. 8.º da EC n. 45/2004**);

20) a aprovação da nomeação de Ministro do STJ pelo *quorum* de **maioria absoluta** dos membros do SF, equiparando-se ao *quorum* de aprovação para a sabatina dos Ministros do STF, e não mais maioria simples ou relativa, como era antes da Reforma (**art. 104, parágrafo único**);

21) a previsão de funcionamento, junto ao STJ: **a)** da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o **ingresso** e **promoção** na carreira; **b)** e do Conselho da Justiça Federal como órgão central do sistema e com poderes correccionais, cujas decisões terão caráter vinculante (**art. 105, parágrafo único, I e II**);

22) no âmbito trabalhista, dentre tantas modificações, podemos destacar: **a)** o aumento da composição do TST de 17 para 27 Ministros, não mais sendo preciso ter de convocar juízes dos TRTs para atuar como substitutos; **b)** em relação ao sistema de composição, reduziram-se as vagas de Ministros do TST oriundos da advocacia e do Ministério Público do Trabalho. Agora eles ocupam somente 1/5, sendo os outros 4/5 preenchidos dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da Magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior; **c)** fixação do número mínimo de 7 juízes para os TRTs; **d)** modificação da competência da Justiça do Trabalho; **e)** previsão de criação da *Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento*

de Magistrados do Trabalho e do *Conselho Superior da Justiça do Trabalho*, sendo que este último deverá ser instalado no prazo de 180 dias; **f)** a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho; **g)** previsão de criação, por lei, do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, integrado pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras receitas (**arts. 111, §§ 1.º, 2.º e 3.º (revogados); 111-A; 112; 114; 115; e arts. 3.º, 6.º e 9.º da EC n. 45/2004**);

23) fixação de novas regras para a Justiça Militar (**art. 125, §§ 3.º, 4.º e 5.º**);

24) assim como fixado para a Magistratura (art. 99, §§ 3.º a 5.º), regulação do procedimento de encaminhamento da proposta orçamentária do Ministério Público e solução em caso de inércia. Proibição de realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais (**art. 127, §§ 4.º, 5.º e 6.º**);

25) nos mesmos termos da Magistratura, diminuição do *quorum* de votação para a perda da garantia da inamovibilidade de 2/3 para **maioria absoluta** (**art. 128, § 5.º, I, “b”**);

26) ampliação da garantia de imparcialidade dos membros do MP: **a)** vedação do exercício de atividade político-partidária, sem qualquer exceção; **b)** vedação do recebimento, a qualquer título ou pretexto, de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; **c)** instituição, conforme já vimos e nos mesmos termos da Magistratura, da denominada *quarentena de saída*, proibindo-os de exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram por aposentadoria ou exoneração pelo prazo de 3 anos (**art. 128, § 5.º, II, “e”, “f” e § 6.º**);

27) conforme vimos para a atividade jurisdicional, também no sentido de se dar maior produtividade e transparência no exercício da função, na busca da

efetividade do processo, destacam-se, para o MP: **a)** a obrigatoriedade de as funções só poderem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição; **b)** a previsão da exigência de 3 anos de atividade jurídica para o bacharel em direito como requisito para o ingresso na carreira do MP (*quarentena de entrada*); **c)** a distribuição imediata dos processos; **d)** e, no que couber, as regras já apresentadas em relação ao art. 93 para a Magistratura (**art. 129, §§ 2.º, 3.º, 4.º e 5.º**);

28) A EC n. 45/2004 foi promulgada em 8 de dezembro de 2004 e entrou em vigor na data de sua publicação, em 31 de dezembro de 2004 (**art. 10 da EC n. 45/2004**).

■ 11.3.3. Principais ações diretas e decisões do STF em relação às novidades introduzidas pela EC n. 45/2004 (ordem cronológica de propositura)

■ **09.12.2004 — ADI 3.367:** questiona a criação do CNJ. O STF, em 13.04.2005, julgando a ação, considerou **constitucional o CNJ**, que foi instalado em 14.06.2005.

■ **20.01.2005 — ADI 3.392:** questiona a necessidade de “comum acordo” introduzida no art. 114, § 2.º, para o dissídio coletivo.

■ **25.01.2005 — ADI 3.395:** questiona a nova regra fixada no art. 114, I. Concedida liminar afastando a competência da Justiça do Trabalho para a “... apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. Em 05.04.2006, a **liminar** concedida foi **referendada** pelo STF. Assim, as “causas instauradas entre o poder público e servidores com vínculo estatutário, ou seja, regidos pela Lei n. 8.112/90, continuam sob **competência da Justiça Federal**” (*Notícias STF*, 05.04.2006 — 18h35). [11](#)

■ **04.03.2005 — ADI 3.423:** questiona a necessidade de “comum acordo” introduzida no art. 114, § 2.º, para o dissídio coletivo e a

competência exclusiva do MPT em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão ao interesse público (art. 114, § 3.º).

■ **10.03.2005 — ADI 3.431:** questiona a necessidade de “comum acordo” introduzida no art. 114, § 2.º, para o dissídio coletivo e a competência exclusiva do MPT em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão ao interesse público (art. 114, § 3.º).

■ **14.03.2005 — ADI 3.432:** questiona a necessidade de “comum acordo” introduzida no art. 114, § 2.º, para o dissídio coletivo.

■ **19.04.2005 — ADI 3.472:** questiona as expressões “e do Ministério Público”, “respectivamente” e “e ao Ministério Público da União”, todas contidas no art. 5.º, § 1.º, da EC n. 45/2004. O STF acolheu a pretensão em sede de liminar, suspendendo a hipótese de indicação supletiva de nomes para o CNMP. Em **28.03.2006**, a ADI foi julgada prejudicada: “(...) os dispositivos atacados — normas transitórias — seriam aplicados à primeira formação do Conselho Nacional do Ministério Público, a ser instalado em 180 dias contados da promulgação da Emenda Constitucional n. 45. O Conselho já está formado. (...) ante a perda do objeto (v.g., ADI 612-QO, Celso, *DJ* 06.05.1994; ADI 2.290-QO, Moreira, *DJ* 29.06.2001), julgo prejudicada a ação direta”.

■ **05.05.2005 — ADI 3.486:** questiona o novo instituto do IDC — Incidente de Deslocamento de Competência — Federalização dos Crimes contra Direitos Humanos, previsto no art. 109, V-A e § 5.º.

■ **11.05.2005 — ADI 3.493:** também questiona o novo instituto do IDC — Incidente de Deslocamento de Competência — Federalização dos Crimes contra Direitos Humanos, previsto no art. 109, V-A e § 5.º. Assim, distribuída por dependência à ADI 3.486.

■ **10.06.2005 — ADI 3.520:** questiona a necessidade de “comum acordo” introduzida no art. 114, § 2.º, para o dissídio coletivo e a competência exclusiva do MPT em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão ao interesse público (art. 114, § 3.º). Distribuída por prevenção à ADI 3.423.

■ **28.06.2005 — ADI 3.529:** questiona a nova regra fixada no art. 114, I.

O Ministro relator determinou o seu apensamento com a ADI 3.395, que, por sua vez, já foi julgada, conforme indicado acima.

■ **08.03.2006 — ADI 3.684:** questiona a competência fixada para a Justiça do Trabalho nos incisos I, IV e IX do art. 114. O STF, por unanimidade, em 1.º.02.2007, deferiu a liminar estabelecendo que a Justiça do Trabalho **não** tem competência para julgar ações criminais (crimes contra a organização do trabalho). Compete à Justiça comum, seja estadual, seja federal, de acordo com a competência, processar e julgar matéria criminal.

■ **03.01.2007 — ADI 3.843:** questiona a vedação de férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Em **04.04.2008**, a petição inicial foi indeferida, já que, segundo o relator, “a ANAMAGES representa tão só — formalmente, pelo menos — o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma impugnada é aplicável a todos os membros integrantes do Poder Judiciário, independentemente da ‘Justiça’ ou ramo estrutural a que pertençam”.

■ **10.08.2009 — ADI 4.282:** A **Associação Nacional dos Defensores Públicos da União — ANDPU** ajuizou a ADI, com pedido de medida cautelar, objetivando seja atribuída interpretação conforme a Constituição ao § 2.º do art. 134, da CF/88, introduzido pela *Reforma do Judiciário*, objetivando o reconhecimento de autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária, tal como estabelecido para a Defensoria Pública dos Estados-Membros. Isso porque a EC n. 45/2004 “assegurou essa autonomia apenas às defensorias públicas estaduais, mantendo a DPU subordinada ao Ministério da Justiça. A ANDPU afirma a necessidade de dar interpretação conforme a Constituição para que seja reconhecida a invalidade da interpretação que tem sido atribuída à emenda constitucional. Acrescenta que o órgão é dependente dos repasses do Ministério da Justiça, que tem outras prioridades” (*Notícias STF*, 17.08.2009). No mesmo sentido da *PEC Paralela da Reforma do Poder Judiciário* (ainda em tramitação), destacamos a EC n. 69/2012, que assegurou autonomia para a *Defensoria Pública do Distrito Federal*, bem como a **EC n. 74/2013** em relação à **Defensoria Pública da União** e as profundas

alterações introduzidas pela EC n. 80/2014 (cf. *item 12.6*). Consequentemente, referida ADI deverá ser julgada prejudicada (*julgamento pendente*).

■ 11.4. ESTATUTO DA MAGISTRATURA

■ 11.4.1. Disposições gerais

José Horácio Cintra Gonçalves Pereira identifica que o enorme “... interesse com as atividades do Poder Judiciário (verdadeira preocupação nacional como se fora o único problema a emperrar o progresso do Brasil) decorre, sem dúvida, do fato de a prestação (de serviço) jurisdicional não atender aos anseios da população: em razão da demora dos processos, dos seus entraves burocráticos, da total falta de aparelhamento moderno, do despreparo dos funcionários e juízes (ainda que de alguns poucos, mas com força suficiente para, ao menos, incentivar as críticas), da falta de recursos financeiros. Enfim, uma gama de deficiências sempre detectadas e diagnosticadas...”. [12](#)

A **Reforma do Judiciário** busca encontrar alguns instrumentos para solucionar os problemas apontados. Conforme estabelece o art. 93 da CF/88, amplamente solidificado pela EC n. 45/2004, **lei complementar**, de iniciativa do **STF**, disporá sobre o **Estatuto da Magistratura**, [13](#) observados os seguintes princípios:

- ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

Neste particular, cabe indagar se o período de **3 anos** deverá ser contado apenas após o bacharelado, ou poderá ser computado durante a graduação, por exemplo, por meio de estágio.

Entendemos que se trata, no fundo, de norma **constitucional de eficácia limitada**, já que “depende” de lei infraconstitucional regulando os seus vetores.

Hugo Nigro Mazzilli destaca que, “sem regulamentação, cremos que o requisito de prévio exercício de atividade jurídica **não é autoaplicável**, de maneira que, se vier a ser exigido em editais de concurso, sem anterior regulamentação, poderá ser questionado por meio de mandado de segurança”.¹⁴

Apenas alertamos que o critério escolhido para a diferenciação não encontra respaldo no princípio da razoabilidade, inexistindo nexos causal.

A redação do texto permite interpretação para os dois lados. Todavia, consideramos não razoável a exigência do requisito dos **3 anos**.

Nesse sentido, segundo Celso Spitzcovsky, “... não se conseguirá apurar a eficiência dos candidatos que acorrerem a essa carreira, revelando-se, pois, como exigência desarrazoada, além de alijar do certame potenciais candidatos os quais poderiam melhor atender ao interesse da coletividade”.¹⁵

No entanto, como noticiado, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o requisito de dois anos de bacharelado em Direito para que candidatos possam se inscrever em concurso público para o cargo de Procurador da República. A decisão, por maioria, declarou constitucional a expressão ‘há pelo menos dois anos’, prevista no art. 187 da Lei Orgânica do Ministério Público (LOMP) — Lei Complementar 75/93” (*Notícias STF*, 11.11.2004 — 18h28 — **ADI 1.040**).

Ainda, o STF, ao analisar o art. 7.º, *caput*, e parágrafo único, da Resolução n. 35/2002, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1.º da Resolução n. 55/2004, do CSMP do DF e Territórios (estabelece a quarentena de entrada de 3 anos a partir do bacharelado, devendo ser comprovada a atividade jurídica), decidiu que “... a norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de selecionar profissionais experientes para o exercício das funções atribuídas aos membros do Ministério Público, asseverando-se que os três anos de atividade jurídica contam-se da data da **conclusão do curso de Direito** e que a expressão ‘atividade jurídica’ corresponde ao desempenho de **atividades**

privativas de bacharel em Direito. Considerou-se, também, que o momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na **data da inscrição no concurso**, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos” (*Inf. 438/STF* — **ADI 3.460/DF**, Rel. Min. Carlos Britto, 31.08.2006, *DJ* de 15.06.2007). [16](#)

Não obstante contrário ao nosso entendimento e ao do próprio STF em relação aos outros concursos que não tenham de comprovar os 3 anos de atividade jurídica (cuja comprovação dos requisitos do edital, para esses outros concursos, vem sendo exigida na data da posse), [17](#) devemos registrar que, infelizmente, sem razoabilidade, parece que a Corte tende a consolidar a interpretação no sentido de que a experiência dos 3 anos seja em cargo privativo de bacharel em direito e, assim, após o bacharelado, devendo ser demonstrada no momento da inscrição no concurso.

Cabe alertar que o tema foi regulamentado pelo CNJ através da **Resolução n. 75, de 12.05.2009**, remetendo o leitor para o seu conteúdo e destacando que o seu art. 23, § 1.º, “a”, determinou que a comprovação deve ser, por outro lado, no momento da **inscrição definitiva**.

CUIDADO: de maneira bastante acertada, o **Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)** editou a **Res. n. 87/2012-CNMP** para estabelecer que a comprovação do período de 3 anos de atividade jurídica deverá ser documentada e formalizada para o ato da **posse** do candidato aprovado em todas as fases do concurso público, e não com o ato de mera inscrição definitiva no respectivo certame.

Isso porque a expressão **“ingresso”** deve ser interpretada como sinônimo de **investidura**, que somente se efetivará com a **posse** no **cargo**.

E o que deve ser entendido por atividade jurídica a ser demonstrada?

De acordo com o art. 59 da Resolução n. 75/2009-CNJ, considera-se **atividade jurídica**:

- aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito;
- o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a

participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado (Lei n. 8.906, de 04.07.1994, art. 1.º) em causas ou questões distintas;

■ o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;

■ o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo de 16 horas mensais e durante 1 ano;

■ o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios.

A referida Resolução **veda**, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a **contagem do estágio acadêmico** ou **qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito**.

Nos termos do art. 59, § 2.º, a comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante **certidão circunstanciada**, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a **utilização preponderante de conhecimento jurídico**, cabendo à Comissão de Concurso, em **decisão fundamentada**, analisar a validade do documento.

Ainda, cumpre observar que a Resolução n. 75/2009-CNJ **retrocede** ao não mais considerar como atividade jurídica (apesar de reconhecer como título — art. 67, VI), a conclusão, com frequência e aproveitamento, de **curso de pós-graduação** (assegurando tal reconhecimento para os cursos comprovadamente iniciados anteriormente à referida Resolução — art. 90).

Nesse particular, José Afonso da Silva, em parecer, afirmou que “alunos de cursos jurídicos não exercem atividades jurídicas”, mas tão somente “atividade de ensino e aprendizado”. Em igual medida, Walber de Moura Agra afirma que “o prazo de três anos de exercício de atividade jurídica é um tempo de maturação, de sedimentação do conhecimento acumulado durante o curso de Direito. Um lapso temporal para que o bacharel possa colocar em prática o que aprendeu durante a sua preparação universitária” (*Notícias STF*, 20.03.2009).

Lembramos, por outro lado, que o art. 2.º da **Resolução n. 40, de 26.05.2009, do CNMP**, ainda admite, como atividade jurídica e para o ingresso nas carreiras do Ministério Público, os cursos de pós-graduação, regra essa que vem sendo discutida na **ADI 4.219**, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em 20.03.2009 (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Em nosso entender, contudo, toda essa questão deveria ter sido regulamentada, necessariamente, por **lei complementar do Congresso Nacional, de iniciativa exclusiva do STF** (competência reservada).

Atenuando a regra trazida pela EC n. 45/2004, o STF vem flexibilizando o preenchimento do requisito dos “3 anos” analisando a **excepcionalidade de alguns casos concretos**, abaixo reproduzidos para a orientação do candidato atento: [18](#)

■ **17.12.2007 — Rcl 4.906/PA — cargo de escrivão de polícia:** analisando o caso concreto, o STF considerou o fato de uma candidata ao concurso público para o provimento do cargo de promotor de justiça do Pará “... ter se formado em Direito mais de 3 anos antes de sua convocação e de, apesar de aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, não ter exercido a advocacia por incompatibilidade com o cargo público que ocupava, qual seja, o de **escrivã da Polícia Federal**, cargo que envolve, **como assinalado por decisão do Conselho Nacional de Justiça — CNJ (Pedido de Providência 1.238)**, o **desempenho de atividades em que são exigidos conhecimentos jurídicos** e para o qual, em **algumas unidades da Federação, seria exigido o bacharelado em Direito**”, o que, se fosse outro o entendimento, em nosso sentir, violaria o princípio da isonomia (Rel. Min. Joaquim Barbosa, *Inf. 493/STF*);

■ **17.12.2007 — Rcl 4.939/PA — cargo de oficial de justiça:** também no concurso de promotor do Pará, o STF considerou o tempo que uma candidata “... exercera como **oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará**, visto que, embora somente em 2007 esse cargo tivesse passado a ser privativo de bacharel em Direito no Estado do Pará (Lei estadual 6.969/2007), já o seria em outras unidades da Federação. Asseverou-se que entendimento contrário implicaria tratamento desigual entre candidatos daquelas unidades federadas e candidatos do Estado do

Pará...” (Rel. Min. Joaquim Barbosa, *Inf.* 493/STF).

Ainda, para esses casos da *Rcl* 4.939/PA e da *Rcl* 4.906/PA, cf. Ementa: “... O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vieram a considerar que os cargos ocupados pelas referidas candidatas, de **oficial de justiça** e de **escrivã de polícia**, preencheriam o requisito previsto no edital, tendo em vista **as atividades por elas desempenhadas**. Situação em que é impossível ao bacharel em direito o exercício da advocacia, dada sua incompatibilidade com o cargo público ocupado” (Rcl 4.906 e Rcl 4.939, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2007, *DJE* de 11.04.2008); [19](#)

■ **03.09.2008 — MS 26.690:** em sede de liminar, o STF atenuou a exigência dos 3 anos em relação à candidata que já era membro do MP Estadual e ainda não tinha completado o período de quarentena. Isso porque ela alegava que, na prática, em muitos casos, exercia as atividades do MPF (LC n. 75/93, arts. 78 e 79). *A liminar foi confirmada pelo Plenário do STF*. O relator Min. Eros Grau entendeu o caso como **excepcional** e justificou o seu voto no sentido de ser o MP uno. O Min. Carlos Ayres Britto, ainda, lembrou que o calendário civil não se confunde com o calendário forense, não havendo a necessidade de comprovar 365 dias por ano, mas 3 anos forenses (*Inf.* 518/STF);

■ **15.05.2008 — MS 26.682:** “... os três anos de atividade jurídica exigidos ao candidato para inscrição definitiva em concurso de ingresso na carreira do Ministério Público contam-se da data de conclusão do curso de Direito, não da colação de grau” (Rel. Min. Cezar Peluso, *DJE* de 27.06.2008);

■ **26.11.2008 — MS 26.681:** analisando o caso concreto, o STF entendeu como preenchido o requisito da quarentena de entrada por faltarem apenas 45 dias para o candidato ao MP comprovar os 3 anos e, ainda, pela demora em conseguir a inscrição na OAB não ter sido ocasionada pelo candidato (*Inf.* 530/STF);

■ **15.10.2009 — MS 27.608:** dentre outros fundamentos (como a análise de certidão circunstanciada juntada pelos impetrantes), o STF, na linha do julgado no MS 26.681, anteriormente indicado, também entendeu como

não razoável a falta de apenas 15 dias para o preenchimento do prazo de 3 anos, especialmente em razão da demora de 2 meses para a implementação da inscrição na OAB (*Inf. 563/STF*).

■ promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: *a)* é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento; *b)* a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;[20](#)

■ aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;

■ na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

■ não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;

■ o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância;

■ previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;

■ o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos

Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4.º;

■ a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40 (sobre o tema, cf. discussão envolvendo a [EC n. 88/2015](#) e a [ADI 5.316](#) no *item 11.4.2*);

■ o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;

■ o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;

■ a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II do art. 93 da CF/88;

■ todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

■ as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública,[21](#) sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

■ nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno;[22](#)

■ a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.

A Reforma do Poder Judiciário consagra, portanto, o [princípio da](#)

ininterruptabilidade da jurisdição, não podendo haver supressão dessa regra sequer por Resolução do CNJ, como ficou muito claro com a edição da Resolução n. 28, de 18.12.2006, que revogou a de n. 24/2006, que, por sua vez, ao modificar a de n. 3/2005, objetivava flexibilizar o disposto no art. 93, XII, da CF/88.

Assim, decidiu o STF em sede de medida cautelar: “... As regras legais que estabeleciam que os magistrados gozariam de férias coletivas perderam seu fundamento de validade pela promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004. **A nova norma constitucional plasmou paradigma para a matéria, contra a qual nada pode prevalecer**. Enquanto vigente a norma constitucional, pelo menos em exame cautelar, cumpre fazer prevalecer a **vedação de férias coletivas de juízes e membros dos tribunais de segundo grau**, suspendendo-se a eficácia de atos que ponham em risco a efetividade daquela proibição...” (ADI 3.823-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.12.2006, *DJ* de 23.11.2007) **(matéria pendente de julgamento pelo STF)**;

- o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;
- os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;
- a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.

Todas essas regras trazidas pela **Reforma do Judiciário** vieram no sentido de dar maior produtividade e transparência à prestação jurisdicional, na busca da efetividade do processo.

■ 11.4.2. EC n. 88/2015 e ADI 5.316 (“PEC da Bengala”)

Como se sabe, existem 3 modalidades de aposentadoria no chamado **Regime Próprio da Previdência Social (RPPS)** no **âmbito da administração pública**, considerando os **servidores titulares de cargos efetivos** da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, bem como os **agentes públicos titulares de cargos vitalícios** (magistrados, membros do MP e membros do Tribunal de Contas) (art. 40, § 1.º, I, II e III): a) por invalidez; b) voluntária; c) compulsória (não estamos considerando os titulares apenas de cargo em comissão, celetistas e temporários que se sujeitam às regras do Regime Geral — art. 40, § 13).

Neste tópico, tratamos apenas da **aposentadoria compulsória** que se implementa em razão de **critério** meramente **objetivo**, qual seja, a **idade**. Ao completá-la, o legislador supõe a **invalidez do servidor público**, assumindo a sua **presunção absoluta de incapacidade para o serviço público**.

Assim, de acordo com o art. 187 da Lei n. 8.112/90, a aposentadoria compulsória será **automática**, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo. Isso significa que o servidor público titular de cargo efetivo, ao completar a idade, **mesmo estando em plena capacidade laboral e sendo contra a sua vontade**, deverá ser forçadamente aposentado e, por isso, essa modalidade é vulgarmente chamada de **“expulsória”**.

A primeira Constituição que estabeleceu a aposentadoria compulsória por idade foi a de **1934**, fixando esta em **68 anos**. Esse parâmetro (68 anos) foi mantido na Constituição de **1937**. A primeira a prever os **70 anos** foi a de **1946**, mantida essa idade nos **textos seguintes**, inclusive na redação originária da de **1988**.

Depois de 26 anos de vigência da atual Constituição, fruto da aprovação da PEC n. 42/2003-SF (que tramitou por quase 12 anos!), conhecida como **“PEC da bengala”**, é promulgada a **EC n. 88/2015**.

Em sua *justificação*, observa-se que “a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando bastante, alterando significativamente o perfil populacional”. Assim, mesmo ao completar 70 anos, o servidor continua com plena capacidade produtiva. A aposentadoria precoce confirma que muitos servidores vão para a iniciativa privada, continuam trabalhando e ainda levam a experiência de anos patrocinada pelo Estado, onerando a Previdência em razão da falta de

contrapartida.

Diante dessa **nova realidade**, a EC n. 88/2015, mantendo a regra sobre a aposentadoria compulsória (70 anos de idade), permitiu que **lei complementar** estabeleça as condições para que o servidor público se aposente aos **75 anos**. A implementação dessa nova situação considerando esse novo parâmetro etário **depende**, necessariamente, da edição de lei complementar (por exemplo, destacamos o *PLS n. 274/2015* do Senador José Serra — pendente).

O art. 100 do ADCT, contudo, prescreve: “até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1.º do art. 40 da Constituição Federal, os **Ministros do STF**, dos **Tribunais Superiores** e do **Tribunal de Contas da União** aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 anos de idade e, assim, **não dependendo de lei complementar, nas condições do art. 52 da Constituição Federal**”.

A AMB, a ANAMATRA e a AJUFE propuseram a **ADI 5.316** (pendente), atacando alguns dispositivos da EC n. 88/2015 em análise.

Em julgamento de **medida cautelar**, o STF determinou que a dispensa de lei complementar prevista na emenda para as citadas autoridades (o art. 100 do ADCT) **não pode ser estendida a outros agentes públicos até que seja editada a lei complementar a que alude o art. 40, § 1.º, II, da CRFB**, a qual, quanto à magistratura, é a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 93 da CRFB (*Estatuto da Magistratura*).

Ainda, o STF, no julgamento da cautelar na ADI 5.316, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que envolvam a aplicação, a magistrados, do art. 40, § 1.º, II, da CRFB e do art. 100 do ADCT, até o julgamento definitivo da ação direta em análise. Além disso, declararam sem efeito todo e qualquer pronunciamento judicial ou administrativo que afaste, amplie ou reduza a literalidade do comando previsto no art. 100 do ADCT e, com base neste fundamento, assegure a qualquer outro agente público o exercício das funções relativas a cargo efetivo **após ter completado setenta anos de idade**.

Outro ponto extremamente polêmico foi a parte final do art. 100 do ADCT

que, apesar de assegurar a aposentadoria compulsória aos 75 anos, determinou que essa nova realidade só poderá ser implementada **nas condições do art. 52, CF**.

Observar “as condições do art. 52” significa dizer que referidas autoridades, para poderem se aposentar com mais de 70 anos, terão que passar por uma **nova sabatina** (art. 52, III, “a” e “b”).

Essa regra de “nova sabatina” foi bastante criticada. A atual previsão estabelece o controle político apenas para o **ingresso** no cargo, e não para a sua continuidade, tendo sido criada uma verdadeira condicionante para a aposentadoria.

Em interessante observação, o *Deputado Luiz Antonio Fleury*, no parecer dado perante a CCJ, na PEC n. 457/2005 (número que tomou na Câmara), determinou ser “incompatível uma nova aprovação pelo Legislativo Federal de Ministro detentor de cargo vitalício, incongruência de inquestionável ameaça aos princípios republicanos que, além de ferir os preceitos mencionados, traduz na fragilização do Poder Judiciário, até mesmo no que diz respeito à imparcialidade, já que o interessado em permanecer no cargo ficaria refém de interesses político-partidários, podendo redundar no comprometimento da liberdade e independência do magistrado”.

No julgamento da medida cautelar, o STF, então, determinou a suspensão da aplicação da expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal” contida no art. 100 do ADCT, por vulnerar as circunstâncias materiais necessárias ao exercício imparcial e independente da função jurisdicional, ultrajando a **separação dos Poderes**, cláusula pétrea inscrita no art. 60, § 4.º, III, da CRFB.

Podemos, então, esquematizar o tema à luz da **EC n. 88/2015** e do julgamento da medida cautelar na **ADI 5.316** (j. 21.05.2015):

■ no **regime próprio da previdência social** no âmbito da administração pública, considerando os servidores titulares de cargos **efetivos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, bem como os agentes públicos titulares de cargos

vitalicios, a aposentadoria compulsória aos **70 anos**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, continua sendo a **regra geral** (art. 40, § 1.º, II);

■ o aumento do limite de idade para **75 anos** depende de **lei complementar** do Congresso Nacional de caráter nacional (tendo em vista a norma constitucional de eficácia limitada introduzida pela EC n. 88/2015);

■ em se tratando da magistratura, essa lei complementar é de iniciativa do STF (art. 93, CF/88, *Estatuto da Magistratura*), pois não se admite que decisões judiciais substituam o Poder Legislativo;

■ até que entre em vigor a lei complementar para a magistratura (art. 93, VI), os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU — e somente eles!, independentemente da lei complementar nacional, por força do comando trazido pela emenda constitucional, aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos **75 anos** de idade, afastando-se a exigência da famigerada nova sabatina, prevista na parte final do art. 100 do ADCT, que teve a sua aplicação suspensa.

■ 11.5. GARANTIAS DO JUDICIÁRIO

As garantias atribuídas ao Judiciário assumem importantíssimo papel no cenário da tripartição de Poderes, assegurando a independência desse órgão, que poderá decidir livremente, sem se abalar com qualquer tipo de pressão que venha dos outros Poderes.

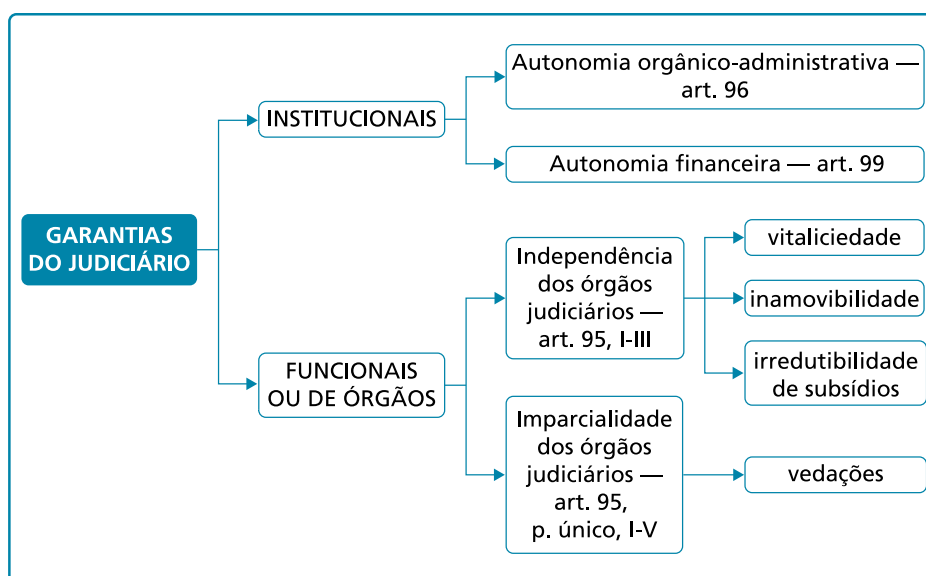
José Afonso da Silva divide tais garantias em:

■ **institucionais**: protegem o Judiciário como um todo, como instituição. Dividem-se em: a) **garantias de autonomia orgânico-administrativa** e b) **garantias de autonomia financeira**;

■ **garantias funcionais ou de órgãos**: “... asseguram a independência (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios) e a imparcialidade dos **membros** do Poder Judiciário (vedações), previstas, aliás, tanto em razão do próprio titular mas em favor ainda da própria

instituição”.[23](#)

Para facilitar o estudo, apresentamos a classificação de modo esquematizado:



■ 11.5.1. Garantias institucionais do Judiciário

■ 11.5.1.1. Garantias de autonomia orgânico-administrativa

A garantia de autonomia orgânico-administrativa manifesta-se na estruturação e funcionamento dos órgãos, na medida em que se atribui aos tribunais a competência para: *a)* eleger **seus órgãos diretivos**, sem qualquer participação dos outros Poderes; *b)* elaborar **regimento interno**; *c)* organizar a **estrutura administrativa interna** de modo geral, como a concessão de férias, licença, dentre outras atribuições. Em relação à autonomia em questão, sugerimos, para as provas, uma leitura atenta do art. 96 e incisos da CF/88.

■ 11.5.1.2. Garantias de autonomia financeira

Estatui o art. 99, *caput*, que ao Poder Judiciário é assegurada, além da já comentada autonomia **administrativa**, também a **autonomia financeira**. Nesse sentido, os tribunais elaborarão suas **propostas orçamentárias** dentro dos

limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

A Constituição prevê regra para o **encaminhamento das propostas orçamentárias**, ouvidos os outros tribunais interessados. Tal procedimento será de competência dos Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais, no âmbito da União, e dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 99, §§ 1.º e 2.º).

A **EC n. 45/2004** (art. 99, § 3.º) fixou que, se esses órgãos não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1.º do art. 99.

Ainda, se as propostas orçamentárias forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1.º do art. 99 citado, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

Dentro dessa política, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites determinados na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Como garantia assecuratória da autonomia financeira, a CF/88 previu em seu art. 168 que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e **Judiciário**, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia **20** de cada mês, **em duodécimos (EC n. 45/2004)**, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.º.

Por fim, dentro dessa ideia de fortalecimento da autonomia financeira do Judiciário, a *Reforma do Judiciário* fixou que as custas e emolumentos serão

destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça (art. 98, § 2.º).

■ 11.5.2. Garantias funcionais do Judiciário (ou de órgãos)

As **garantias funcionais**, na classificação proposta por José Afonso da Silva, como sistematizado anteriormente, dividem-se em dois grupos: o primeiro engloba as **garantias de independência dos órgãos judiciários** (dos membros, dos magistrados), quais sejam: a **vitaliciedade**, a **inamovibilidade** e a **irredutibilidade de subsídios** (art. 95, I, II e III). O segundo grupo abarca as **garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários**, conforme vedações previstas no art. 95, parágrafo único. Vejamo-las. [24](#)

■ 11.5.2.1. Garantias de independência dos órgãos judiciários

■ 11.5.2.1.1. Vitaliciedade

Prevista no art. 95, I, a **vitaliciedade** significa dizer que o **magistrado** (e, como veremos, os membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas) só perderá o cargo (uma vez vitaliciado) por **sentença judicial transitada em julgado**, sendo-lhe asseguradas todas as garantias inerentes ao processo jurisdicional.

Ao contrário dos magistrados, os demais servidores públicos são **estáveis**, ou seja, podem perder o cargo não só por decisão judicial como também por processo administrativo e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. [25](#)

A vitaliciedade, em primeiro grau de jurisdição, só será adquirida após **2 anos** de efetivo exercício do cargo, desde que, naturalmente, o magistrado supere o denominado **estágio probatório**. Nos 2 primeiros anos, para o juiz, que ingressou na carreira por meio de concurso de provas e títulos, ocupando o

cargo de **juiz substituto** (art. 93, I), a perda do cargo dependerá de deliberação do tribunal a que estiver vinculado (art. 95, I).

Todos os membros dos **tribunais** têm a garantia da vitaliciedade, independentemente da forma de acesso. Mesmo que um advogado ou membro do MP integre a carreira da Magistratura, por exemplo, através da regra do **quinto constitucional** — art. 94 (estudaremos adiante), no exato momento da **posse** adquirirá a vitaliciedade, não tendo de passar por qualquer estágio probatório.

Devemos lembrar, ainda, que a regra da **vitaliciedade** (uma vez vitaliciado, o magistrado só perderá o cargo por **sentença judicial transitada em julgado**) apresenta exceções:

- **Ministros do STF:** na hipótese de **crime de responsabilidade** serão julgados pelo **SF** (art. 52, II);

- **Conselheiros do CNJ:** de acordo com o art. 11, § 3.º, do Regimento Interno do *CNJ — Conselho Nacional de Justiça* (art. 103-B da CF/88), os Conselheiros não integrantes das carreiras da magistratura terão os mesmos direitos, prerrogativas, deveres, impedimentos constitucionais e legais, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura, no que couber, enquanto perdurar o mandato (Anexo da Resolução n. 67, de 03.03.2009, que aprovou o novo RI/CNJ). Contudo, o art. 52, II, da CF/88 estabelece que os membros do CNJ também serão julgados pelo **SF** por **crime de responsabilidade**.

Interessante discussão surge em relação à possibilidade de o CNJ declarar a perda do cargo de magistrados vitalícios.

Uma vez vitaliciados, a regra é clara: os magistrados só poderão perder o cargo por **sentença judicial transitada em julgado**. Portanto, na medida em que os atos do CNJ têm natureza administrativa, não nos parece possível haver revisão de vitaliciamento de magistrado pelo Conselho.

Esse entendimento foi externado pelo CNJ no julgamento do **PCA 267**, do Estado do Tocantins, que teve como relator o Conselheiro Paulo Lôbo. Em referido PCA, a OAB/TO pretendia a anulação do *IV Concurso Público para*

provimento do cargo de juiz de direito substituto do Estado de Tocantins, realizado em 2004, com 18 vagas disponíveis, e dos respectivos decretos judiciais de nomeação. Alegava que os seis candidatos aprovados que tomaram posse em 2004, do total de 1.600 candidatos de várias unidades da Federação, apresentavam relações diretas com membros do Poder Judiciário do Estado, comprovadas com certidões.

Por unanimidade, o CNJ, de maneira acertada, consagrou o entendimento de que não poderia analisar a questão. Isso porque, esclarece o Relator, “... **após a vitaliciedade, apenas sentença judicial transitada em julgado pode determinar a perda do cargo, o que subtrairia a competência deste Conselho**. Se os juízes não tivessem obtido a vitaliciedade, então a deliberação de tribunal seria de natureza administrativa, o que permitiria a apreciação pelo CNJ da matéria da invalidade do concurso. Todavia, parece-me que a questão da eventual invalidade do concurso, que determinaria a perda dos cargos dos juízes com vitaliciedade, **apenas poderia ser enfrentada em processo judicial**, pois a regra constitucional atraiu para este todos os atos que a antecederam. **A garantia da vitaliciedade é inviolável por decisão administrativa...**”.

■ 11.5.2.1.2. *Inamovibilidade*

Pela regra da **inamovibilidade** (art. 95, II), garante-se ao juiz a impossibilidade de remoção, sem seu consentimento, de um local para outro, de uma comarca para outra, ou mesmo sede, cargo, tribunal, câmara, grau de jurisdição.

Essa regra **não é absoluta**, pois, como estabelece o art. 93, VIII, o magistrado poderá ser removido (além de colocado em disponibilidade e aposentado), por **interesse público**, fundando-se tal decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. [26](#)

A grande questão a ser analisada é se os **juízes substitutos** gozam da garantia da inamovibilidade, ou se, em razão de sua natureza (de substituir), poderão ser

removidos de acordo com as necessidades discricionárias apontadas pelos Tribunais.

Tal problemática foi levada ao CNJ (*PCA n. 2008.10.00.001873-3*), que decidiu, no caso concreto, que a prerrogativa da inamovibilidade não se aplica aos juízes substitutos, mesmo que já vitaliciados.

Contra referida decisão do CNJ, foi impetrado, no STF, o **MS 27.958**, julgado em **17.05.2012**.

O Min. Marco Aurélio, **vencido**, apresentou argumentos interessantes, denegando a ordem no mérito “por considerar que a inamovibilidade não guardaria pertinência com o cargo de juiz substituto, haja vista que o juiz seria assim nomeado para atender às necessidades de substituição. Ressaltava que assentar que o juiz substituto gozaria da prerrogativa inerente à inamovibilidade descaracterizaria o próprio cargo por ele ocupado e que eventual abuso do poder se resolveria em outro campo, sendo que cada Estado-membro poderia ter a própria organização judiciária, a limitar a movimentação do juiz substituto” (*Inf. 666/STF*).

Contudo, a maioria dos Ministros (o julgamento foi por **8 x 1**) entendeu, **de maneira acertada**, que a **garantia da inamovibilidade se aplica aos juízes substitutos**. Vejamos:

“EMENTA: (...). A **inamovibilidade é**, nos termos do art. 95, II, da CF, **garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular como também o substituto**. O magistrado só poderá ser removido por designação, para responder por determinada vara ou comarca ou para prestar auxílio, com o seu consentimento, ou, ainda, se o interesse público o exigir, nos termos do inciso VIII do art. 93 do Texto Constitucional” (**MS 27.958**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.05.2012, Plenário, *DJE* de 29.08.2012).

O importante contraponto a ser feito em relação ao juiz substituto é o juiz titular, e não o vitalício. Assim, é possível que o juiz seja vitalício e ainda substituto, sem que, mesmo que substituto, deixe de ter a garantia da inamovibilidade.

A Constituição não fez nenhuma exigência em relação à garantia da inamovibilidade, exigindo prazo de 2 anos apenas para a vitaliciedade.

Assim, desde a posse, o juiz substituto deve ter a garantia de não ser removido para fora da *unidade judiciária* em que está formalmente lotado. Trata-se de *unidade de competência judicante*, adstrita a uma base territorial geograficamente determinada e predefinida.

Dessa forma, muito embora o “papel” do juiz substituto seja o de substituir, deverá exercer a sua função **dentro da sua circunscrição judiciária**, definida, no âmbito estadual, pelo *Código Judiciário* de cada unidade federativa.

A circunscrição judiciária será constituída da reunião de comarcas contíguas da mesma região, uma das quais será a sua sede, e, assim, a substituição poderá dar-se nas respectivas comarcas.

O que não se pode aceitar é a remoção indistinta do juiz substituto para circunscrições diversas, com o risco de perseguição do magistrado e flagrante violação, inclusive, ao princípio do juiz natural.

Podemos concluir, portanto, que a decisão do STF, ao aceitar a garantia da inamovibilidade para o juiz substituto, prestigia a Constituição, **evitando a sua transformação em juiz itinerante**, bem como eventuais pressões que possa sofrer dos órgãos internos da própria judicatura.

■ 11.5.2.1.3. Irredutibilidade de subsídios

Previsto no art. 95, III, o subsídio dos magistrados (forma de remuneração, consoante a EC n. 19/98) não poderá ser reduzido, garantindo-se, assim, o livre-exercício das atribuições jurisdicionais. [27](#)

Lembramos que o STF já se pronunciou no sentido de tratar-se de **garantia nominal**, e não real, ou seja, os magistrados não estão livres da corrosão de seus subsídios pela inflação.

Tal como se verifica para os servidores públicos em geral, o subsídio mensal dos membros do Judiciário, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do

STF. Hão de se observar, outrossim, nos termos da regra trazida pela EC n. 41/2003 (**Reforma da Previdência**), os denominados subtetos, que, no âmbito do Judiciário estadual e distrital, será o subsídio máximo pago aos Desembargadores do TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF.

Buscando **amenizar** o impacto da Reforma, a **EC n. 47/2005** (que tramitou como a “PEC Paralela da Previdência”) acrescentou o § 11 ao art. 37, nos seguintes termos: “**não serão computadas**, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do *caput* deste artigo, **as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei**”.

O art. 4.º da EC n. 47/2005, por sua vez, estabelece que, enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da CF, **não será computada**, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do *caput* do mesmo artigo, **qualquer parcela de caráter indenizatório**, assim definida pela **legislação em vigor na data de publicação da EC n. 41/2003**.

Em julgamento **liminar** da **ADI 3.854**, o STF diferenciou o **subsídio** máximo da Magistratura estadual, correspondente a 90,25% do subsídio pago aos Ministros do STF, do **teto de remuneração** (subsídio mais alguma vantagem funcional), que, por isonomia à Magistratura federal (art. 93, V), corresponderá a 100% do subsídio mensal dos Ministros do STF. [28](#)

O subsídio, como forma de remuneração, está sujeito a **tributação** (arts. 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I), devendo ser fixado em **parcela única** (art. 37, X e XI, c/c o art. 39, § 4.º) e obedecer ao escalonamento a que se refere o art. 93, V. [29](#)

■ 11.5.2.2. **Garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários**

Aos magistrados foram impostas algumas **vedações**, delimitadas nos incisos do parágrafo único do art. 95. Trata-se de **rol taxativo, exaustivo, por restringir direitos**. Assim, aos juízes é vedado: [30](#)

■ exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma

de magistério;[31](#) e 32

- receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

- dedicar-se à atividade político-partidária;[32](#)

- receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei (**EC n. 45/2004**);

- exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (**EC n. 45/2004** — a denominada *quarentena de saída*).

■ 11.5.3. Prerrogativa de foro: o magistrado aposentado tem direito a foro especial por prerrogativa de função?

Não.

Conforme esquematizamos no *item 10.4.15*, os magistrados têm prerrogativa de foro na hipótese de crime comum e de responsabilidade, durante o exercício da função judicante.

A grande questão que se coloca é saber se o **magistrado aposentado** continuaria com essa prerrogativa.

- **argumentos pela manutenção da prerrogativa de foro:** em primeiro lugar, na linha do voto do Min. Menezes Direito, o fato concreto que está sendo analisado aconteceu enquanto o magistrado ainda exercia a sua função judicante, portanto, antes da aposentadoria. Enquanto juiz de direito, mesmo aposentado, continua com a **vitaliciedade**, não perdendo o cargo, mantida estaria a prerrogativa de foro. Além do mais, há previsão nesse sentido no art. 48 do *Estatuto de Roma* (TPI). Já o Min. Eros Grau diferenciou a **prerrogativa que decorre da função**, como no caso de mandato eletivo temporário, da **prerrogativa que decorreria do cargo**, no caso do magistrado que é vitalício;

■ **argumentos contrários à manutenção da prerrogativa de foro:**

lembrando jurisprudência discutida e estudada no *item 9.9.2.3*, findo o exercício da função, a prerrogativa de foro deixa de existir (salvo no caso de *fraude processual*, estudada no referido item). Segundo o Min. Lewandowski, ainda, com base no RE 291.485/RJ “... o foro especial por prerrogativa de função tem por objetivo o resguardo da função pública; que o magistrado, no exercício do ofício judicial, goza da prerrogativa de foro especial, **garantia que está voltada não à pessoa do juiz**, mas aos **jurisdicionados**; e que, não havendo mais o exercício da função judicante, não há de perdurar o foro especial, haja vista que o resguardo dos jurisdicionados, nesse caso, não é mais necessário. Ressaltou, ainda, que o provimento vitalício é o ato que garante a permanência do servidor no cargo, aplicando-se apenas aos que integram as fileiras ativas da carreira pública” (*Inf. 495/STF*).

A tese da manutenção da prerrogativa de foro parecia bastante defensável, até porque, conforme visto, a **vitaliciedade** persiste mesmo com a **aposentadoria**. Assim, em edições anteriores, chegamos a sustentá-la, mas com limites, ou seja, somente em relação a crimes e atos praticados antes da aposentadoria, enquanto o magistrado ainda exercia a sua nobre função judicante. Estender a prerrogativa para os atos praticados após a aposentadoria não teria, em nosso entender, qualquer fundamento constitucional.

O STF, por maioria, resolveu a questão no julgamento dos **REs 546.609 e 549.560**, reafirmando a orientação jurisprudencial no sentido de que **os magistrados que se aposentam perdem a prerrogativa de foro, mesmo em relação a atos praticados no exercício da função e em virtude desta**, destacando-se os seguintes argumentos:

■ “o foro especial por prerrogativa de função teria por objetivo o **resguardo da função pública**;

■ o magistrado, no exercício do ofício judicante, gozaria da prerrogativa de foro especial, garantia voltada **não à pessoa do juiz**, mas aos **jurisdicionados**; e

■ o foro especial, ante a **inexistência do exercício da função, não deveria perdurar**, haja vista que a proteção dos jurisdicionados, nesse caso, não seria mais necessária” (RE 549.560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.03.2012, Plenário, *Inf. 659/STF*).

■ 11.6. ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO

■ 11.6.1. Órgãos de convergência e órgãos de superposição

As regras do Poder Judiciário vêm previstas nos arts. 92 a 126 da CF/88. Conforme esquematizado no item seguinte e constatado pelo organograma do *item 11.6.5*, pode-se afirmar que o **STF** e os Tribunais Superiores (**STJ, TST, TSE e STM**) são **órgãos de convergência**, têm sede na Capital Federal (Brasília) e exercem jurisdição sobre todo o território nacional, nos termos do art. 92, § 2.º, da CF/88.

Denominam-se **órgãos** ou **centros de convergência** visto que, segundo ensina Dinamarco, “cada uma das Justiças especiais da União (Trabalhista, Eleitoral e Militar, acrescente-se), tem por cúpula seu próprio Tribunal Superior, que é o responsável pela última decisão nas causas de competência dessa Justiça — ressalvado o controle de constitucionalidade, que sempre cabe ao Supremo Tribunal Federal. Quanto às causas processadas na Justiça Federal ou nas locais, em matéria infraconstitucional a convergência conduz ao Superior Tribunal de Justiça, que é um dos Tribunais Superiores da União embora não integre Justiça alguma; em matéria constitucional, convergem diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Todos os Tribunais Superiores convergem unicamente ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da Justiça brasileira e responsável final pelo controle de constitucionalidade de leis, atos normativos e decisões judiciais”.³³

E quais, então, seriam os denominados pela doutrina **órgãos de superposição**? Na medida em que **não pertencem a nenhuma Justiça**, podemos classificar o **STF** e o **STJ** (Tribunais da União) não só como órgãos de

convergência, como já visto, mas, também, como **órgãos de superposição**. Isso porque, embora não pertençam a nenhuma Justiça, as suas decisões se sobrepõem às decisões proferidas pelos órgãos inferiores das Justiças comum e especial. As decisões do **STJ** se sobrepõem àquelas da Justiça Federal comum, da Estadual e daquela do Distrito Federal e Territórios, ao passo que as decisões do STF se sobrepõem a todas as Justiças e Tribunais.

■ 11.6.2. Justiças: comum e especial

Além dos órgãos de superposição (STF e STJ), temos as diversas **Justiças**, divididas em comum e especial (ou especializada).

■ **Justiça comum:**

a) *Justiça Federal* (Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais — arts. 106 a 110, bem como a criação de Juizados Especiais nos termos da Lei federal n. 10.259/2001 — art. 98, § 1.º, da CF/88);

b) *Justiça do Distrito Federal e Territórios* (Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios, organizados e mantidos pela União — arts. 21, XIII, e 22, XVII, que também criará os Juizados Especiais e a Justiça de Paz);

c) *Justiça Estadual comum* (ordinária) (art. 125 — juízos de primeiro grau de jurisdição, incluídos os Juizados Especiais [34](#) — art. 98, I — e a Justiça de Paz — art. 98, II; [35](#) bem como os de segundo grau de jurisdição, compostos pelos Tribunais de Justiça. Lembrar que a possibilidade de criação dos Tribunais de Alçada, nos termos do art. 96, II, “c”, da CF/88, e 108 da LOMN, [36](#) não mais existe em razão do art. 4.º da **EC n. 45/2004**).

■ **Justiça especial:**

a) *Justiça do Trabalho*: composta pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST; Tribunais Regionais do Trabalho — TRTs e pelos Juízes do Trabalho (Varas do Trabalho) (arts. 111 a 116); [37](#)

b) *Justiça Eleitoral*: composta pelo Tribunal Superior Eleitoral — TSE;

Tribunais Regionais Eleitorais — TREs, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais (arts. 118 a 121);

c) *Justiça Militar da União*: Superior Tribunal Militar — STM e Conselhos de Justiça, Especial e Permanente, nas sedes das Auditorias Militares (arts. 122 a 124);

d) *Justiça Militar dos Estados, do Distrito Federal e Territórios*:³⁸ Tribunal de Justiça — TJ, ou Tribunal de Justiça Militar — TJM, nos Estados em que o efetivo militar for superior a 20.000 integrantes e, em primeiro grau, pelos juízes de direito togados (juízes de direito da Justiça Militar Estadual) e pelos Conselhos de Justiça, com sede nas auditorias militares — art. 125, §§ 3.º, 4.º e 5.º — **EC n. 45/2004**).

■ 11.6.3. Competência penal *versus* competência civil

Dentre todas as Justiças acima apontadas, somente a **Justiça do Trabalho não tem competência penal** (julga e concilia apenas dissídios individuais e coletivos oriundos das relações trabalhistas).

Até o advento da **EC n. 45/2004**, as **Justiças Militares** (União, Estados e a do Distrito Federal e Territórios) só tinham competência penal, e não civil, vale dizer, julgavam apenas e tão somente os crimes militares definidos em lei. Os atos disciplinares eram julgados pela Justiça Federal (atos praticados por integrantes das Forças Armadas) ou pelos Juízes da Fazenda Pública (atos praticados por militares estaduais), ou mesmo Justiça comum estadual, quando inexistentes as Varas Especializadas da Fazenda Pública estadual em razão de sua não instituição.

Com o novo § 5.º introduzido pela *Reforma do Judiciário* ao art. 125 da CF/88, a **Justiça Militar Estadual** (e veja, somente a **estadual**, podendo, em nosso entender, ser ampliada para a do **DF e Territórios**), através de seus juízes de direito togados (e não pelos Conselhos, como se verá), passou a ter competência para julgar as ações judiciais contra **atos disciplinares militares**, portanto, de natureza **civil**, e não mais exclusivamente penal, como acontecia

antes da Reforma.

As demais, **Federal, Eleitoral, Estaduais** e a do **Distrito Federal e Territórios**, têm tanto competência penal como civil.

■ 11.6.4. Juizados Especiais: algumas particularidades

■ 11.6.4.1. *Não cabimento de Recurso Especial para o STJ e o cabimento de Rcl*

A **Lei n. 12.153, de 22.12.2009**, dispôs sobre os **Juizados da Fazenda Pública**.³⁹

Assim, o **sistema** dos **Juizados Especiais** dos **Estados** e do **Distrito Federal** passou a ser formado pelos:

■ **Juizados Especiais Cíveis;**

■ **Juizados Especiais Criminais;**

■ **Juizados Especiais da Fazenda Pública.**

Em se tratando de **Juizados Especiais**, de acordo com a lei, o segundo grau de jurisdição é exercido pelas **Turmas Recursais**, compostas por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (**Colégio Recursal**) (cf. arts. 41, § 1.º, e 82 da Lei n. 9.099/95).

A Lei n. 12.153/2009 não inova em relação a essa regra, estabelecendo, nos termos de seu art. 17, que as Turmas Recursais do *Sistema dos Juizados Especiais* são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, com mandato de 2 anos, e integradas, preferencialmente, por juízes do Sistema dos Juizados Especiais. A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento, não sendo permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da Turma Recursal.

Por sua vez, a Lei n. 12.665/2012 dispôs sobre a criação de **estrutura**

permanente para as **Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais**, criando os respectivos cargos. De acordo com o seu art. 2.º, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias são formadas, cada uma, por 3 juízes federais titulares dos cargos de Juiz Federal de Turmas Recursais e por 1 juiz suplente.

Mais tecnicamente, poderíamos dizer que as Turmas Recursais funcionam como **segunda instância recursal**, podendo ser enquadradas como **órgãos colegiados de primeiro grau**.

Assim, como não se trata de Tribunal, mas de **Turma Recursal**, o STJ firmou o seguinte entendimento na **Súmula 203**: “não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais”.

Isso porque o art. 105, III, da CF/88 confere competência para o STJ julgar, em **recurso especial**, as causas decididas, em única ou última instância, pelos **TRFs** ou pelos **TJs** dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, **não fazendo menção às causas decididas pelas Turmas de Colégio Recursal**, que diferem dos TRFs e TJs.

Avançando, apesar de não caber recurso especial, os Ministros do STF, no julgamento dos EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* de 14.09.2009, entenderam que cabe **reclamação**, com fundamento no art. 105, I, “f”, para o **STJ**, quando a decisão de Turma Recursal de Juizados Estaduais violar a interpretação da legislação infraconstitucional federal dada pela jurisprudência do STJ (cf. *Inf. 557/STF*).

Alerta-se que, no âmbito dos **juizados estaduais**, ainda não foi criada a *Turma de Uniformização da Jurisprudência*, prevista no *PL n. 16/2007-CD*, realidade, por outro lado, para o âmbito dos **Juizados Federais** (Lei n. 10.259/2001, inclusive com recurso para a referida Corte — art. 14, § 4.º) e, agora, dos **Juizados Especiais da Fazenda Pública** (arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/2009).

Outro entendimento, segundo a Min. Ellen Gracie, levaria a decisões divergentes das proferidas pelo STJ, provocando verdadeira **insegurança jurídica** e **prestação jurisdicional incompleta**.

Nesse sentido, o STJ editou a **Resolução n. 12, de 14.12.2009**, dispondo, em seu art. 1.º, que as reclamações destinadas a **dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil** (“julgamento por amostragem”) serão oferecidas no prazo de **15 dias**, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo.

A previsão da figura do *amicus curiae* (art. 2.º, III, da Resolução n. 12/2009-STJ) mostra-se bastante adequada no sentido de pluralização do debate e legitimação das decisões.

■ 11.6.4.2. Cabimento de RE para o STF

Apesar de não caber recurso especial para o STJ, o STF editou a **Súmula 640**, afirmando a possibilidade do RE: “é cabível **recurso extraordinário** contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por **turma recursal de juizado especial cível e criminal**”.

Perceba que o art. 102, III, diferentemente do art. 105, III, fala em “causa decidida”, e não em “causa decidida por tribunal”. Assim, englobadas estão as causas decididas por Turma de Colégio Recursal.

Devemos alertar, contudo, que o **Plenário Virtual do STF**, em 19.03.2015, no julgamento de 3 recursos extraordinários com agravo (**ARE 835.833** — responsabilidade pelo inadimplemento de obrigação em contrato privado; **ARE 837.318** — revisão contratual; e **ARE 836.819** — indenização decorrente de acidente de trânsito), estabeleceu **entendimento bastante restritivo** para o conhecimento de recursos extraordinários contra decisões de **juizados especiais cíveis estaduais**. Vejamos a ementa de um desses julgados e que serviu de base para a explicitação da orientação da Corte em relação ao instituto da repercussão geral em recursos dessa natureza (conforme destacou o Min. Teori Zavascki, até 2014, apesar do alto número de REs interpostos, **apenas 9** tiveram a repercussão geral reconhecida):

“EMENTA: 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em **relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica**, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas **excepcionalmente** essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da **repercussão geral** de que tratam o art. 102, § 3.º, da Constituição (...). 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais **Cíveis** da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) **o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica**. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral...” (ARE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 19.03.2015, Plenário, *DJE* de 26.03.2015).

■ 11.6.4.3. **Cabimento de HC e MS contra ato de juizado especial — superação da S. 690/STF**

O STF editou, em sessão plenária de 24.09.2003, a **Súmula 690**: “compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de *habeas corpus* contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais”.

CUIDADO: em novo julgamento, o STF entendeu por **superada** a Súmula 690, definindo a competência do **TJ local** na hipótese de *habeas corpus* contra decisão de turma recursal.

Em relação a este último entendimento firmado na **S. 690 do STF**, o Ministro Marco Aurélio já havia suscitado questão de ordem no julgamento do **HC 83.228**, no sentido de saber se ainda prevalecia tendo em vista a redação

conferida ao art. 102, I, “i”, pela EC n. 22/99, que fala em ato de “**Tribunal Superior**”. Tinha, pois, por superado o entendimento, no que foi acompanhado pelo Ministro Carlos Velloso. *Em um primeiro momento*, o STF, por maioria, julgou **válida** a interpretação fixada na S. 690 e conheceu do *habeas corpus* (cf. *Inf. STF* ns. 327 e 394 e *Notícias STF*, 1.º.08.2005).

Contudo, em nova e posterior manifestação sobre a matéria, o STF, finalmente, concluiu por superada a tese fixada no enunciado da Súmula 690.

Trata-se do julgamento do **HC 86.834**, em **23.08.2006**, no qual, por 8 x 3, o STF, aderindo à tese, então vencida do Min. Marco Aurélio, decidiu como competente o **TJ local** para o julgamento de *habeas corpus* contra decisão de **Turma Recursal**.

“(…) Entendeu-se que, em razão de competir aos tribunais de justiça o processo e julgamento dos juízes estaduais nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (**CF, art. 96, III**), a eles deve caber o julgamento de *habeas corpus* impetrado contra ato de turma recursal de juizado especial criminal. Asseverou-se que, em reforço a esse entendimento, tem-se que a competência originária e recursal do STF está prevista na própria Constituição, inexistindo preceito que delas trate que leve à conclusão de competir ao Supremo a apreciação de *habeas corpus* ajuizados contra atos de turmas recursais criminais. Considerou-se que a **EC n. 22/99** explicitou, relativamente à alínea ‘i’ do inciso I do art. 102 da CF, que cumpre ao Supremo julgar os *habeas corpus* quando o coator for tribunal superior, constituindo paradoxo admitir-se também sua competência quando se tratar de ato de turma recursal criminal, cujos integrantes sequer compõem tribunal...” (HC 86.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 23.08.2006, *Inf. 437/STF*).[40](#)

Essa nova orientação, no que respeita ao *habeas corpus* (e observa-se que o STF decidia **apenas** em relação ao *habeas corpus*, não chegando a analisar, no precedente citado, a hipótese do *mandado de segurança*), está, de vez, pacificada, destacando-se, por exemplo, as decisões tomadas, monocraticamente, pelo Ministro Gilmar Mendes, nos *Habeas Corpus* ns. 87.835, 89.432, 89.460 e 89.495, declinando competência para o **Tribunal de**

Justiça; bem como julgamento proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa, ao determinar a remessa do HC 89.923 para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira, ainda, no mesmo sentido: HC 85.240, Rel. Min. Carlos Britto, j. 14.02.2008, *DJE* de 19.09.2008; HC 86.026-QO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.09.2006, *DJ* de 20.10.2006; HC 89.630-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.09.2006; e, mais recentemente, HC 101.014-MC/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.10.2009, bem como HC 104.893, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento monocrático em 06.08.2010.

E como fica a solução para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato dos juízes dos Juizados Especiais cíveis (1.ª instância e Turma Recursal)?

Em determinado julgado, o STF decidiu, diferentemente do que fora firmado em relação ao *habeas corpus*, tendo por base o art. 21, VI, da LC n. 35/79 (*LOMAN — Lei Orgânica da Magistratura Nacional*), ser competente a **própria Turma Recursal de Juizado Especial** para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra seus atos, afastando-se a alegada competência originária da Suprema Corte para o julgamento do *writ*, bem como a do Tribunal de Justiça (adotando-se, assim, regra distinta da fixada para o *habeas corpus* (MS 24.691-QO/MG, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 04.12.2003, *Inf.* 332/STF). Nesse sentido:

“EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. **A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal**” (MS-QO 24.691/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, *DJ* de 24.06.2005)

Esse entendimento em relação ao **mandado de segurança**, por unanimidade, veio a ser reafirmado pelo Pleno do STF:

“EMENTA: As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os

juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a **turma recursal** para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o **mandado de segurança substitutivo de recurso**. Primazia da **simplificação do processo judicial** e do **princípio da razoável duração do processo**” (RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.11.2011, Plenário, DJE de 27.02.2012).

O art. 21, VI, da LC n. 35/79 (LOMAN) estabelece ser competência privativa dos “Tribunais” julgar, **originariamente**, os **mandados de segurança contra seus atos**, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.

Assim, o precedente para o *mandado de segurança* se funda na interpretação dada ao art. 21, VI, da LOMAN. E percebam que o dispositivo legal se refere apenas ao **MS**, e não ao **HC**, motivo pelo qual surgiram regras distintas para cada remédio constitucional.

No STJ, a Min. *Maria Thereza de Assis Moura* assim se posicionou (CC 38.020/STJ): “Na questão de ordem supracitada, o entendimento vencedor considerou que, mesmo estando os membros das Turmas Recursais subordinados administrativamente ao Tribunal respectivo, elas devem ser consideradas como órgãos independentes e de segundo grau de jurisdição. Desta forma, o vínculo administrativo não define a competência do Tribunal para o julgamento do **mandado de segurança** impetrado contra ato de magistrado que atua em Turma Recursal. Pelo contrário, por serem as Turmas Recursais funcionalmente independentes dos Tribunais, a solução foi dada pela interpretação analógica do art. 21, inciso VI, da Lei Complementar n. 35/79, *in verbis*: Art. 21 — Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI — julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”.

Essa interpretação foi mantida no julgamento do MS 25.087 ED/SP-STF, Rel. Min. Carlos Britto, 21.09.2006 (*Inf. 441/STF*), determinando a Suprema Corte o encaminhamento dos autos para o tribunal competente, no caso, a

Turma Recursal (mudando, inclusive, a jurisprudência que, até então, não acolhia a necessidade de indicar o órgão julgador competente).

Pode-se afirmar, portanto, que o STF **não** tem competência originária para o julgamento de **MS** contra ato dos juízes dos Juizados ou das Turmas dos Colégios Recursais dos Juizados Especiais, sobretudo em razão da regra do art. 102, I, “d”, que prevê a competência originária do STF **somente** contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.⁴¹ A competência, como já decidido, para o **mandado de segurança** (e, insisto, segundo o **STF**, apenas para o **MS**, já que a regra do *HC* é outra, no caso, o **TJ**) será da própria **Turma Recursal**. Confira:

‘EMENTA: COMPETÊNCIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do **mandado de segurança** contra ato de Turma Recursal cabe à própria **Turma**, **não havendo campo para atuação** quer de **Tribunal de Justiça**, quer do **Superior Tribunal de Justiça**. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n. 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence...” (AI 666.523 AgR/BA, Rel. Min. Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2010, 1.^a Turma, *DJe* de 02.12.2010).

E pacífica é a jurisprudência do **STJ**, materializada na **S. 376**, editada pela *Corte Especial*, em **18.03.2009**, e que tem o seguinte teor: “competete a **Turma Recursal** processar e julgar o **mandado de segurança** contra ato de juizado especial”, e, analisando os precedentes, mesmo se o ato coator tiver sido praticado por Juiz da Turma Recursal (cf., no STJ, CC n. 38.020 ou CC n. 39.950). Prevalece, dessa forma, a regra fixada no art. 21, VI, da LOMAN, conforme indicado acima.

O STJ firmou entendimento flexibilizando a regra contida na citada S. 376, na hipótese de discussão *não sobre o mérito da decisão proferida pela Turma Recursal*, mas sobre a **competência** dos Juizados, quando, então, o conflito seria resolvido pelo **TJ** (cf. CC 39.950/BA, Corte Especial, Rel. Min. Castro Filho, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, *DJe* de 06.03.2008 e, seguindo essa

mesma linha, por exemplo, o RMS 30.170/SC, 3.^a Turma, j. 05.10.2010, Rel. Min. Nancy Andrighi).

CUIDADO: esse entendimento foi expressamente **afastado** pela 1.^a Turma do STF no julgamento do AI 666.523 AgR/BA, em 26.10.2010, quando, então, de acordo com a ementa citada acima, pacificou-se no STF que a competência será sempre da própria Turma Recursal para julgar mandado de segurança.

Contudo, com o máximo respeito, avançando a regra fixada no *MS 24.691* e agora à luz da tese adotada no *HC 86.834*, não temos por coerente o julgamento de *mandado de segurança* contra ato de Turma Recursal pela própria Turma Recursal, pelo menos, ao que parece, seguindo o mesmo entendimento do HC 86.834.

Não é pelo fato de ser **MS** que o entendimento deva ser diferente do **HC**, com base, simplesmente, no art. 21, VI, da LOMAN. Ambas são ações constitucionais e buscam o seu fundamento diretamente na Constituição, no caso, para nós, no art. 96, III, e na inexistência de previsão específica para outro Tribunal.

A nosso ver a melhor interpretação é aquela que entende ser competente para o julgamento de mandado de segurança contra ato de juiz de direito do Juizado a Turma do Colégio Recursal. Todavia, contra atos ou decisões das Turmas dos Colégios Recursais dos Juizados Especiais, a competência para o julgamento do MS (e não se está falando em recurso contra o julgamento da Turma Recursal), assim como para o julgamento do HC e desde que **originária**, seria do **TJ local**.⁴²

CUIDADO: essa nossa proposta, em relação ao **mandado de segurança**, **não foi acolhida nem pelo STF nem pelo STJ**. Portanto, para as provas de concursos, adotar o entendimento de que a competência para o julgamento do MS é da própria Turma Recursal. Apenas na hipótese de *HC* é que a competência para o julgamento de ato de Turma Recursal seria do TJ.

Proposta de esquematização da matéria em relação aos Juizados:

■ **S. 203/STJ** — “não cabe recurso especial contra decisão proferida por

órgão de segundo grau dos juizados especiais”. Trata-se, no caso, de decisões das Turmas de Colégio Recursal, que, por não serem Tribunais, não encontram guarida na regra contida no art. 105, III, da CF/88. Cabe, no entanto, até que seja aprovado o *PL 16/2007-CD*, conforme definiu o STF (RE 571.572), **reclamação**, com fundamento no art. 105, I, “f”, para o **STJ**, quando a decisão de Turma Recursal de Juizados Estaduais violar a interpretação da legislação infraconstitucional federal dada pela jurisprudência do STJ;

■ de decisão de Turma de Colégio Recursal pode caber tanto o HC para o TJ local como, na mesma linha e como interpretamos (*vide* ressalva abaixo), MS a ser julgado pelo TJ local (**competência originária**). Trata-se de interpretação ampla da regra geral de que o TJ local julga ato de juízes de direito e com fundamento no art. 96, III, da CF/88. Nesse sentido, na medida em que a Turma Recursal é composta por juízes de direito, constituindo-se, assim, Órgão Colegiado, justificada está a competência (originária) para o TJ local. **CUIDADO:** esse entendimento em relação ao **mandado de segurança** contraria a S. 376/STJ, bem como o posicionamento do STF, que indicam, como órgão competente, a própria Turma Recursal para o julgamento do mandado de segurança. Assim, em relação ao *habeas corpus*, segundo o STF, a competência para julgar ato da Turma Recursal seria do **TJ** (cf. **HC 86.834**). Contudo, em se tratando de *mandado de segurança*, a competência é da **própria Turma Recursal** (cf. **MS-QO 24.691/MG** — sendo esse o entendimento a ser adotado nas provas de concursos);

■ de acórdão do TJ local, se adotarmos o posicionamento fixado no referido *HC*, na hipótese de *habeas corpus* decidido em **única instância** (competência originária, já que o ato atacado é de Turma Recursal, e não em grau de recurso), nos termos do art. 105, II, “a”, da CF/88, caberá **ROC — Recurso Ordinário Constitucional** para o **STJ**, quando denegatória a decisão;

■ de acórdão do TJ local, na hipótese de *mandado de segurança* decidido em **única** instância (competência originária), e aceita a nossa interpretação no

sentido da competência do TJ local — **lembrando que não é essa a adotada pelo STF**, nos termos do art. 105, II, “b”, da CF/88 —, caberá **ROC — Recurso Ordinário Constitucional** para o **STJ**, quando denegatória a decisão;

■ na medida em que a orientação adotada pelo STF na hipótese de **mandado de segurança** é a competência da própria Turma Recursal, caberá, no máximo, **recurso extraordinário** para o **STF** ou, enquanto não aprovado o *PL n. 16/2007-CD*, citado acima, eventualmente, **reclamação** para o **STJ**;

■ **S. 640**: “é cabível **recurso extraordinário** contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por **turma recursal de juizado especial cível e criminal**”. Assim, não confundir RE com as ações constitucionais de MS e HC tratadas nos itens anteriores (ver perspectiva restritiva de cabimento indicada no *item 11.6.4.2* para o conhecimento de recursos extraordinários contra decisões de **juizados especiais cíveis estaduais**);

■ contra ato dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais (juízos de primeira instância), caberá HC ou MS para a *Turma Recursal*. Nesse sentido, destacamos o **Enunciado n. 62** do *XV Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais do Brasil* (26 a 28.05.2004, Florianópolis — SC): “Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o *habeas corpus* impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais”, assim como a citada S. 376/STJ;

■ a mesma interpretação deve ser feita para o julgamento de MS e HC em relação aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal (Lei n. 10.259/2001), destacando que o julgamento de atos das Turmas Recursais, no caso o *habeas corpus*, será realizado não pelo TJ local, mas pelo **TRF** competente. No caso de *mandado de segurança*, conforme vimos e com as discussões que propusemos, o entendimento é o de que seria competente a **própria Turma Recursal**. Finalmente, em igual sentido, contra ato do Juiz do Juizado Especial Federal poderá caber MS ou HC para a

Turma Recursal Federal;

■ **UM ALERTA:** de acordo com a jurisprudência do STF (e contra o nosso entendimento), **não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95**. Isso porque, justificou-se, “a Lei 9.099/95 está voltada à promoção de **celeridade** no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da **irrecorribilidade das decisões interlocutórias**, inarredável. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do CPC (a decisão foi proferida à luz do CPC/73), sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CB), uma vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado”.[43](#)

■ **11.6.4.4. Ação de indenização em razão do fumo: incompetência dos Juizados — complexidade da causa**

O STF analisou pedido de indenização formulado por ex-fumante que alegava ter fumado cigarros por aproximadamente 44 anos, tornando-se dependente do produto, criticando, inclusive, a propaganda, que seria enganosa.

O Plenário do STF, por votação unânime, entendeu que os juizados especiais **não seriam competentes** para a análise da demanda, tendo em vista a **complexidade da causa**, embora o valor formulado não ultrapassasse o “teto” dos juizados.

Como se sabe, o art. 98, I, CF/88, estabelece que a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão **juizados especiais**, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução, além das infrações penais de menor potencial ofensivo, das **causas cíveis de menor complexidade**. Nesse sentido:

“A excludente da competência dos juizados especiais — complexidade da controvérsia (art. 98 da CF) — há de ser sopesada em face das causas de pedir

constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. Competência. Ação indenizatória. **Fumo. Dependência. Tratamento. Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais**” (RE 537.427, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.04.2011, Plenário, DJE de 17.08.2011).

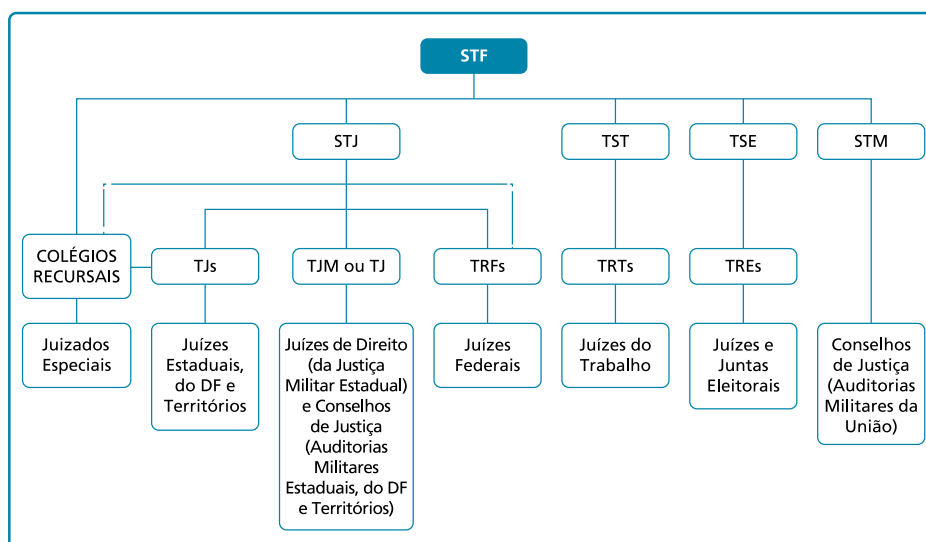
■ 11.6.4.5. Juizados e a Lei Maria da Penha

De modo específico, a **Lei n. 11.340/2006** (*Lei Maria da Penha*), além de outras providências, criou mecanismos para **coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher**, nos termos do § 8.º do art. 226 da Constituição Federal, da *Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres* e da *Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher*, dispondo sobre a criação dos **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**, bem como alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.

O STF, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em **09.02.2012**, julgou procedente a **ADC 19** para declarar, dentre outros, a constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), tendo por fundamento o **princípio da igualdade** e da **proporcionalidade**, bem como o **combate ao desprezo às famílias**, sendo considerada a **mulher** a sua **célula básica**.

Assim, aos **crimes** praticados com **violência doméstica e familiar contra a mulher**, independentemente da pena prevista, **não se aplica a Lei n. 9.099/95** (*Juizados Especiais Cíveis e Criminais*). Assim, conforme anotou o Min. Fux em seu voto, “ao suposto ofensor, não serão conferidos os institutos da suspensão condicional do processo, da transação penal e da composição civil dos danos” (cf. *item 19.9.5*).

■ 11.6.5. Organograma do Poder Judiciário [44](#)



■ 11.7. A REGRA DO “QUINTO CONSTITUCIONAL”

O art. 94 da CF/88 estabelece que **1/5 (20%)** dos lugares dos **TRFs**, dos **Tribunais dos Estados** e do **Distrito Federal** e **Territórios** será composto de membros do **Ministério Público**, com mais de **10 anos** de carreira, e de **advogados** de **notório saber jurídico** e de **reputação ilibada**, com mais de **10 anos** de efetiva atividade profissional, indicados em **lista sêxtupla** pelos órgãos de representação das respectivas classes.⁴⁵

Apesar de o art. 94 só se referir explicitamente aos tribunais acima mencionados, a “regra do quinto” está prevista, também, para os **tribunais do trabalho**⁴⁶ (arts. 111-A, I; 115, I) e o seu procedimento orienta a composição do **STJ** (art. 104, parágrafo único, lembrando a particularidade de que, nesse caso, os advogados e membros do Ministério Público representam **1/3**, e não 1/5, do Tribunal. Explicitando, a **indicação** é que se dá na **forma** da “regra do quinto”, e não a quantidade de Ministros provenientes da advocacia e do Ministério Público que, no caso, implementa-se, se é que assim podemos denominar, de acordo com uma particular regra do “terço” — cf. *item 11.8.2*).

Está **errado**, portanto, dizer que todos os tribunais brasileiros devam observar a regra do “quinto” (seja o seu procedimento ou mesmo a quantidade de 20% dos integrantes provenientes da advocacia e do MP), pois, como será estudado no *item 11.8*, os outros tribunais não listados acima têm um procedimento

próprio de composição.

■ **procedimento:** os órgãos de representação das classes dos advogados⁴⁷ e Ministério Público⁴⁸ elaboram lista sêxtupla, ou seja, indicam 6 nomes que preencham os requisitos acima citados. Recebidas as indicações, o tribunal para o qual foram indicados forma lista tríplice (escolhe 3 dos 6). Nos 20 dias subsequentes, o Chefe do Executivo (em se tratando de Tribunal Estadual, o Governador de Estado; na hipótese do TJ do DF e Territórios, o Presidente da República, e para indicação ao TRF, também o Presidente da República) escolherá 1 dos 3 para nomeação.

Não nos parece possam as Constituições estaduais estabelecer outras formalidades além das já expressamente previstas no art. 94 da CF, por exemplo, a necessidade de aprovação do escolhido pelo Chefe do Executivo pela “maioria absoluta da Assembleia Legislativa do Estado”, conforme estabeleceu o parágrafo único do art. 63 da CE/SP, na redação determinada pela EC n. 25/2008.

O procedimento é bem simples e está regulamentado de modo **exaustivo** pelo art. 94, CF/88: a escolha pelo **órgão de classe** de 6 nomes que preencham os requisitos constitucionais (*lista sêxtupla*); formação de *lista tríplice* pelo **tribunal** (Judiciário) e, dentre os 3, escolha de 1 pelo **Executivo** para nomeação, sem que o nome escolhido (pelo Executivo) tenha de passar por qualquer outro procedimento, como a eventual sabatina do Legislativo (**que não participa do processo de escolha**), não se aplicando, assim, o art. 52, III, da CF à regra do “quinto”, nem mesmo por analogia.⁴⁹

Duas importantes questões já foram decididas pelo STF:

■ **na hipótese de não existirem membros do MP que preencham os requisitos constitucionais, como compor a lista sêxtupla? “Seria possível compor ou complementar a lista sêxtupla com membros do Ministério Público que ainda não tenham completado 10 anos na carreira?”**

O STF entendeu que **SIM**, no julgamento da **ADI 1.289-EI**, declarando a constitucionalidade do *item IV da Decisão Normativa do CSMPT*, tomada na

4.^a Reunião Ordinária, em 23.10.1993, que autoriza a complementação das listas de candidatos ao preenchimento dos cargos de juiz dos TRTs (veja composição do TRT no *item 11.8.4.2* seguinte) com os candidatos que tenham tempo inferior a dez anos na hipótese de inexistência de pelo menos seis candidatos com esse requisito temporal. [50](#)

■ **e se a lista sêxtupla apresentada contiver nomes que não preenchem os requisitos constitucionais?**

O texto de 1988, em relação aos anteriores, inova ao transferir a **escolha originária** dos nomes, que era dos tribunais, para os órgãos de classe. Como visto, o Tribunal limita-se a reduzir a lista de 6 nomes para 3 e, assim, reduzido ao universo já trazido pelo órgão de classe, encaminhar para o Executivo, que reduzirá de 3 para 1.

Diferentemente da situação particular descrita no julgamento da ADI 1.289-EI, que analisou a inexistência, em dado momento, de integrantes do MP com mais de 10 anos de carreira, indagamos: e se o Tribunal entender que um ou mais nomes da lista sêxtupla encaminhada pelo órgão de classe não preenchem os requisitos constitucionais, como o notório saber jurídico e a reputação ílibada?

Entregar lista com nome de pessoa que não preenche os requisitos do art. 94 é o mesmo que entregar lista **incompleta**, com menos de 6 nomes.

Nesses termos, o STF entendeu que o Tribunal pode **recusar** a lista sêxtupla “... desde que fundada a recusa em **razões objetivas**, declinadas na motivação da deliberação do órgão competente do colegiado judiciário. Nessa hipótese ao Tribunal envolvido jamais se há de reconhecer o poder de substituir a lista sêxtupla encaminhada pela respectiva entidade de classe por outra lista sêxtupla que o próprio órgão judicial componha, ainda que constituída por advogados componentes de sextetos eleitos pela Ordem para vagas diferentes. A solução harmônica à Constituição é a devolução motivada da lista sêxtupla à corporação da qual emanada, para que a refaça, total ou parcialmente, conforme o número de candidatos desqualificados: dissentindo a entidade de classe, a ela restará questionar em juízo, na via processual adequada, a rejeição parcial ou total do

tribunal competente às suas indicações” (**MS 25.624**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.09.2006, *DJ* de 19.12.2006). [51](#)

Nessa linha, a Corte entendeu como justificada a recusa, pelo TJ/SP, de lista sêxtupla encaminhada pela OAB/SP em relação a 2 advogados: **a)** um respondia a processo criminal; **b)** o outro não teria notável saber jurídico, já que havia sido reprovado em 10 concursos para a Magistratura (**Rcl 5.413**, Rel. Min. Menezes Direito, j. 10.04.2008, *DJE* de 23.05.2008).

■ 11.8. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

■ 11.8.1. Supremo Tribunal Federal (STF)

■ 11.8.1.1. STF — aspectos históricos [52](#)

NOMENCLATURA	MOMENTO HISTÓRICO PREPONDERANTE	PERÍODO DE ATIVIDADES
■ Casa da Suplicação do Brasil	■ Fase colonial	■ 10.05.1808 até 08.01.1829
■ Supremo Tribunal de Justiça	■ Império	■ 09.01.1829 até 27.02.1891
■ Supremo Tribunal Federal	■ República	■ 28.02.1891 até os dias atuais

	DISPOSITIVO	NOMENCLATURA	INTEGRANTES	REQUISITO
--	-------------	--------------	-------------	-----------

ALVARÁ RÉGIO DE 1808	■ art. IV	■ Casa da Suplicação do Brasil	■ 2352	■ não h previsão explícita n Constituição de requisito para investidura
CONSTITUIÇÃO DE 1824	■ art. 163	■ Supremo Tribunal de Justiça	■ não houve previsão na Constituição ■ a Lei de 18.09.1828 fixou em 17 Juizes Letrados	■ “Juízes Letrados, tirados das Relações p suas antiguidades; e serão condecorado com o Títul do Conselho Não havi previsão d prévia aprovação pelo Senado
			■ 15 Juizes	■ cidadãc de notáv saber reputação, elegíveis par o Senado devendo haver

CONSTITUIÇÃO DE 1891	■ art. 56	■ Supremo Tribunal Federal	■ 15 Juízes ■ o Decreto n. 19.656/31 reduziu para 11 o número de integrantes	aprovação por este órgão Durante Governo Provisório de Getúlio Vargas (03.11.1930-20.07.1934), os Ministros foram nomeados sem a prévia aprovação do Senado
CONSTITUIÇÃO DE 1934	■ art. 73	■ Corte Suprema	■ 11 Ministros, podendo esse número ser elevado por lei até 16	■ brasileiros natos de notável saber jurídico reputação ilibada alistados eleitores, não devendo ter salvo os magistrados, menos de 35 nem mais de 65 anos de idade, com aprovação do Senado Federal

CONSTITUIÇÃO DE 1937	■ art. 97	■ Supremo Tribunal Federal	■ 11 Ministros, podendo esse número ser elevado por lei até 16	■ brasileiro natos d notável sabe jurídico reputação ilibada, não devendo te menos de 3! nem mais d 58 anos d idade, cor aprovação d Conselho Federal. Não havia previsã de aprovaçã pelo Senado Assim, váric Ministros foram nomeados sem ess importante controle político
CONSTITUIÇÃO		■ Supremo	■ 11 Ministros, podendo esse número ser	■ brasileiro (art. 129, ns. e II — nato: acrescente- se), maiore de 35 anos de notáv

CONSTITUIÇÃO DE 1946	■ art. 98	■ Supremo Tribunal Federal	número ser elevado por lei ■ AI n. 2/65 elevou para 16	de notável saber jurídico e reputação ilibada , devendo haver aprovação pelo Senado Federal
CONSTITUIÇÃO DE 1967	■ art. 113	■ Supremo Tribunal Federal	■ 16 Ministros ■ esse número foi reduzido para 11 Ministros, de acordo com o AI n. 6/69	■ brasileiro natos, maiores de 35 anos, de notável saber jurídico reputação ilibada , devendo haver aprovação pelo Senado Federal
EC N. 1/69	■ art. 118	■ Supremo Tribunal Federal	■ 11 Ministros	■ maiores de 35 anos, de notável saber jurídico reputação ilibada , devendo haver aprovação

				Federal
CONSTITUIÇÃO DE 1988	■ art. 101, <i>caput</i>	■ Supremo Tribunal Federal	■ 11 Ministros	■ cidadão com mais d 35 e menc de 65 anos d idade, c notável sabe jurídico reputação ilibada , devendo haver aprovação pela maior absoluta c Senado Federal

Antes da vinda da família real para o Brasil, esclarece o Conselheiro Ribas, “competia à Casa de Suplicação (de Lisboa, acrescente-se) interpretar as ordenações, e leis por meio de assentos com força obrigatória. Estes assentos eram tomados na mesa grande por ocasião de dúvida proposta por alguns dos desembargadores, juízes da causa, ou por glosa do chanceler, por entender que a sentença infringia expressamente as ordenações ou o direito”. [53](#)

Passando D. João a residir no Brasil (tendo em vista a transferência da família real em razão da invasão das terras portuguesas por tropas napoleônicas) e, na medida em que, diante dessa situação, encontrava-se interrompida a comunicação com Portugal, o Príncipe Regente, mediante **Alvará Régio de 10.05.1808**, institui a “**Casa da Suplicação do Brasil**”, que se caracterizou como o primeiro órgão de cúpula da Justiça no Brasil, marca da fase colonial. [54](#)

Durante o regime monárquico, a **Lei de 18.09.1828** criou o **Supremo Tribunal de Justiça** (09.01.1829-27.02.1891), cumprindo a previsão contida no art. 163 da Constituição de 1824, que sucedeu à *Casa da Suplicação do Brasil*.

Em seguida, editado pelo Governo Provisório da República, o **Decreto n. 848, de 11.10.1890**, organizou o **Supremo Tribunal Federal**, órgão de cúpula do Judiciário, nos termos dos arts. 55 e 56 da Constituição Republicana de 1891, efetivamente instalado em 28.02.1891.

A **Constituição de 1934**, por sua vez, alterou a denominação para **Corte Suprema**. A **Carta de 1937** retomou a designação **Supremo Tribunal Federal (STF)**, mantida em todas as Constituições que seguiram, inclusive na de **1988**.

Finalmente, nessa escalada evolutiva, a **Constituição da República de 1988** instituiu o **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, instalado em 07.04.1989 (Lei n. 7.746/89), reservando ao **STF** a posição de **órgão de cúpula de todo o Judiciário e, especialmente, de guarda e defesa da Constituição**. [55](#)

■ 11.8.1.2. STF — regras gerais

■ **composição:** 11 Ministros;

■ **investidura:** o Presidente da República escolhe e indica o nome para compor o STF, devendo ser aprovado pelo Senado Federal, pela **maioria absoluta** (sabatina no Senado Federal). [56](#) Aprovado, passa-se à nomeação, momento em que o Ministro é vitaliciado;

■ **requisitos para ocupar o cargo de Ministro do STF:** a) ser brasileiro nato (art. 12, § 3.º, IV); b) ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade (art. 101); c) ser cidadão (art. 101, estando no pleno gozo dos direitos políticos); d) ter notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 101);

■ **tem de ser jurista o Ministro do STF?:** o art. 56 da Constituição de **1891** falava somente em **notável saber**, sem qualificá-lo. A Constituição de **1934** (art. 74) passou a qualificar o **notável saber** de **jurídico**. Diante da permissão da Constituição de 1891, o STF já chegou a ter Ministro que não era jurista, vale lembrar o médico *Candido Barata Ribeiro*, nomeado

pelo Presidente *Floriano Peixoto*, por decreto de 23.10.1893, em razão da vaga ocorrida com o falecimento do Barão de Sobral, tomando posse em 25.11.1893.

O Senado da República, contudo, em sessão secreta de 24.09.1894, negou a aprovação do nome de Barata Ribeiro, nos termos do Parecer da *Comissão de Justiça e Legislação*, que considerou desatendido o requisito de “notável saber jurídico” (DCN de 27.09.1894, p. 1136). Assim, Barata Ribeiro deixa o cargo de Ministro do STF em 29.09.1894, tendo ficado por pouco mais de 10 meses (o Ministro que por menos tempo permaneceu no STF [República], só “perdendo” para o Ministro Herculano de Freitas, que permaneceu por 3 meses e 16 dias).

Portanto, atualmente e desde o parecer de *João Barbalho*, de 1894, passou-se a entender que todo Ministro do STF terá de ser, necessariamente, **jurista**, tendo cursado a faculdade de **direito**.⁵⁷

■ **competências do STF:** a) originária (art. 102, I, “a” a “r”);⁵⁸ b) recursal ordinária (art. 102, II); e c) recursal extraordinária (art. 102, III).

O STF reconheceu o **princípio da reserva constitucional de competência originária** e, assim, toda a atribuição do STF está explicitada, taxativamente, no art. 102, I, da CF/88.⁵⁹

Ainda, na hipótese de o STF não conhecer a sua competência originária, deverá, nos termos do art. 113, § 2.º, do CPC/73 (com correspondência no art. 64, § 3.º, CPC/2015), e do art. 21, § 1.º, do *RISTF*, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, **indicar o órgão que repute competente** para o julgamento do feito ajuizado originariamente, atribuição essa autorizada, inclusive, ao Relator monocraticamente (cf. Pet. 3.986-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 25.06.2008, *Inf. 512/STF*).

■ **11.8.1.3. STF — destaques às novidades trazidas pela EC n. 45/2004 (“Reforma do Judiciário”)**

■ **homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequatur**

às cartas rogatórias: transferência de competência do STF para o **STJ** no tocante à homologação de sentenças estrangeiras e à concessão de *exequatur* às cartas rogatórias (art. 102, I, “h”, revogada; art. 105, I, “i”, e art. 9.º da EC n. 45/2004).

■ **nova hipótese de cabimento do RE:** ampliação da competência do STF para o julgamento de recurso extraordinário quando *julgar válida lei local contestada em face de lei federal*. Muito se questionou sobre essa previsão. Observa-se que está **correta**, uma vez que, no fundo, quando se questiona a aplicação de lei, tem-se, acima de tudo, conflito de constitucionalidade, já que é a CF que fixa as regras sobre competência legislativa federativa. Por outro lado, quando se questiona a validade de ato de governo local em face de lei federal, estamos, acima de tudo, diante de questão de legalidade a ser enfrentada pelo STJ, como mantido na reforma (**arts. 102, III, “d”, e 105, III, “b”**).

■ **CNJ e CNMP:** em razão da natureza dos institutos e de seus membros, é natural que tenha sido fixada a competência do STF para processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (art. 102, I, “r”).

■ **repercussão geral:** criação do requisito da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso para o conhecimento do recurso extraordinário. Essa importante regra vai evitar que o STF julgue brigas particulares de vizinhos, como algumas discussões sobre “assassinato” de papagaio ou “furto” de galinha, já examinadas pela mais alta Corte (**art. 102, § 3.º**).

A matéria foi regulamentada na **Lei n. 11.418, de 19.12.2006**.

De fato, trata-se de importante instituto seguindo a tendência a erigir o STF a verdadeira **Corte Constitucional** e, também, mais uma das técnicas trazidas pela *Reforma do Judiciário* na tentativa de solucionar a denominada “Crise do STF e da Justiça”.

A técnica funciona como verdadeiro **“filtro constitucional”**, permitindo que o STF não julgue processos destituídos de repercussão geral, limitando, dessa forma, o acesso ao Tribunal.

A lei estabeleceu um **critério objetivo**, presumindo-se a repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.

Além disso, o art. 543-A, § 1.º, do CPC/73 (art. 1.035, § 1.º, CPC/2015) traz um **critério subjetivo** ao estabelecer que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

Trata-se, portanto, de mais um **requisito de admissibilidade do recurso extraordinário** que deverá ser demonstrado pela parte recorrente em **preliminar**.

Em interessante tendência de aproximação do controle difuso aos efeitos do controle concentrado (influência do Ministro Gilmar Mendes), o art. 543-A, § 5.º, do CPC/73, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, dispõe que, sendo negada a existência da repercussão geral (do caso concreto, individualizado), **a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica**, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (cf. art. 1.035, § 8.º, CPC/2015).

Parece, então, ser mais uma hipótese de **súmula impeditiva de recurso**, no caso do recurso extraordinário, servindo como “barreira” para o acesso ao STF de todos os casos que tratem da mesma matéria, ou melhor, de recurso com fundamento em idêntica controvérsia.

A possibilidade de manifestação de terceiros estranhos ao processo (*amicus curiae*), ao “pluralizar o debate constitucional”, confere maior **efetividade e legitimação social** às decisões *erga omnes* do STF (na hipótese de impedir o processamento de outros recursos extraordinários sobre a mesma tese).

O reconhecimento da inexistência da repercussão geral terá de ser manifestado por 2/3 dos Ministros do STF (pelo menos 8 dos 11 Ministros).

Antes de se mandar o processo para análise do Pleno, contudo, proceder-se-á a uma verificação prévia da repercussão geral, por uma das Turmas do STF (5 Ministros).

Assim, na dicção do art. 543-A, § 4.º, do CPC/73, se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário e proceder-se-á à análise do mérito do recurso extraordinário (sem correspondência no CPC/2015).

Por outro lado, se entender a Turma, por menos de 4 votos, que o caso concreto apresenta repercussão geral (ou, ainda, se entender, por consequência, que o caso não tem repercussão geral), essa decisão (sobre a eventual inexistência da repercussão geral) caberá ao Pleno do STF, devendo ser suscitado um *incidente de análise de repercussão geral*, nos termos do Regimento Interno do STF e da Lei n. 11.418/2006, que regulamentou a matéria.

A nosso ver o procedimento deve seguir a linha do incidente de inconstitucionalidade no controle difuso, suscitando-se uma questão de ordem.

Considerando o Pleno que há repercussão geral, ou não, deverá sedimentar a tese em **súmula de repercussão geral**, que, para nós, deve ser oficialmente estabelecida pelo STF e numerada como um novo instituto para, inclusive, orientar o processamento de recursos extraordinários futuros.

Assim, segundo o art. 543-A, § 7.º, do CPC/73, a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no *Diário Oficial* e valerá como acórdão (correspondência idêntica no art. 1.035, § 11, CPC/2015).

Por fim, cumpre destacar importante técnica de julgamento por **amostragem**, sobrestando os demais recursos extraordinários considerados semelhantes.

Isso porque, havendo **multiplicidade de recursos** com fundamento em idêntica controvérsia, caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STF, **sobrestando** os demais até o pronunciamento definitivo da Corte (art. 543-B, § 1.º, do CPC/73 — cf. art. 1.036, § 1.º, CPC/2015).

Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos.

Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que

poderão declará-los prejudicados ou retratar-se (perceba-se, assim, o impacto do julgamento do caso individual perante recursos que tenham teses jurídicas já decididas).

Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o STF, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.

Sem dúvida, o instituto da repercussão geral vem-se mostrando uma importante técnica na busca de concretizar o **princípio da efetividade do processo** (art. 5.º, LXXVIII).

■ **Repercussão geral: AI 664.567 (Inf. 472) e RE 579.431 (Inf. 510) — procedimento fixado pelo STF**

O STF já estabeleceu alguns procedimentos para a implantação do instituto da repercussão geral, o que passamos a reproduzir:

■ “A existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é pressuposto de admissibilidade de todos os recursos extraordinários, inclusive em matéria penal”. Assim, embora regulamentado no CPC, o requisito deve ser observado em qualquer RE, tanto em matéria cível como criminal, trabalhista, eleitoral, militar etc.

■ “Exige-se preliminar formal de repercussão geral, sob pena de não ser admitido o recurso extraordinário”.

■ Contudo, “... a exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas **só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03.05.2007**, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, do *RISTF*” (*Inf. 472/STF*), que regulamentou a matéria. [60](#)

■ Se o RE for anterior à data de 03.05.2007, “a possibilidade de devolução fica condicionada ao reconhecimento da presença da repercussão geral da matéria. Negada a repercussão, recusa-se o recurso extraordinário (§ 3.º do art. 102, da Constituição Federal)”.

■ “A verificação da existência da preliminar formal é de competência

concorrente do Tribunal, Turma Recursal ou Turma de Uniformização de origem e do STF”.

■ “A análise sobre a existência ou não da repercussão geral, inclusive o reconhecimento de presunção legal de repercussão geral, é de **competência exclusiva** do STF”.

■ O STF, em importante precedente, regulamentou a aplicação da repercussão geral em relação à jurisprudência já pacificada pela Corte. Nesse sentido, foi “(...) aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a) manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela renovação da discussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a adoção, pelos órgãos judiciais *a quo*, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3.º, do CPC/73. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário...” (RE 579.431-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.06.2008, DJE de 24.10.2008).

■ **11.8.1.4. STF — procedimento para deliberação e encaminhamento de solicitações de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPR)**

O **sistema de solução de controvérsias** no MERCOSUL foi consolidado, em 18.02.2002, com a assinatura do **Protocolo de Olivos**, que criou o **Tribunal Permanente de Revisão (TPR)**, considerando “a necessidade de garantir a correta interpretação, aplicação e cumprimento dos instrumentos fundamentais do processo de integração e do conjunto normativo do MERCOSUL, de forma consistente e sistemática”.⁶¹

De acordo com o art. 4.º do Dec. CMC n. 37/2003, *Regulamento do*

Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias (RPO), as **opiniões consultivas** poderão ser solicitadas pelos Tribunais Superiores dos Estados-Partes com jurisdição nacional.

Pois bem, nesse sentido, de maneira bastante interessante, o **STF** (no caso, o “Tribunal Superior”) **regulamentou o procedimento nos termos da Emenda Regimental n. 48/2012**, que introduziu o art. 7.º, VIII, bem como os arts. 354-H a 354-M, ao *RISTF*.

Trata-se de **procedimento administrativo**, e não jurisdicional, e que poderá ser instaurado pelo juiz da causa ou alguma das partes,⁶² deixando clara a regra regimental de que a opinião consultiva emitida pelo TPR **não terá caráter vinculante nem obrigatório**.

A solicitação de opinião consultiva deve originar-se necessariamente de **processo em curso perante o Poder Judiciário brasileiro** e restringe-se exclusivamente à vigência ou interpretação jurídica do *Tratado de Assunção*, do *Protocolo de Ouro Preto*, dos *protocolos e acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção*, das *Decisões do Conselho do Mercado Comum (CMC)*, das *Resoluções do Grupo Mercado Comum (GMC)* e das *Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM)* (art. 354-H, *RISTF*)

Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, a solicitação será encaminhada ao Tribunal Permanente de Revisão, com cópia para a Secretaria do Mercosul, e para as demais Cortes Supremas dos Estados Partes do Mercosul (art. 354-L, *RISTF*).

■ 11.8.2. Superior Tribunal de Justiça (STJ)

■ **composição:** pelo menos 33 Ministros (art. 104);

■ **investidura:** os Ministros serão escolhidos e nomeados pelo Presidente da República, após serem sabatinados pelo Senado Federal e aprovados pelo voto da **maioria absoluta** (art. 104, parágrafo único, com a redação determinada pela **EC n. 45/2004**), igualando-se ao *quorum* da sabatina para os Ministros do STF;

■ **requisitos para o cargo:** a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) ter mais de 35 e menos de 65 anos; c) ter notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 104);

■ **composição dos Ministros:** 1/3 dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais; 1/3 dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça; 1/6 dentre advogados; e 1/6 dentre membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente;

■ **procedimento:** no caso dos juízes dos Tribunais Regionais Federais e dos desembargadores dos Tribunais de Justiça, o STJ elaborará lista tríplice, enviando-a ao Presidente da República, que indicará um e o nomeará após aprovação do Senado Federal. No caso dos advogados e membros do Ministério Público, serão eles indicados na forma das regras para o “quinto constitucional”, anteriormente apresentadas, segundo o art. 94 da CF/88, ou seja, o órgão de classe elabora a lista sêxtupla, o STJ escolhe 3 dentre os 6 (lista tríplice) e o Presidente da República escolhe 1 da referida lista formada e o nomeia, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (sabatina). Alertamos que, apesar de se determinar a aplicação da regra do art. 94, o **número** de Ministros do STJ provenientes da advocacia e do Ministério Público é de **1/3**, e não 1/5, do Tribunal. Ou seja, o que se observa é apenas o procedimento de escolha, e não o número (que, no caso, não é de 20%, mas de 1/3, o que poderia, então, nesse aspecto, ser denominado regra do “terço”);

■ **os Ministros oriundos da magistratura (TRFs e TJs) terão de ser egressos da magistratura da carreira?** O STF, por maioria de votos, no julgamento da **ADI. 4.078**, entendeu, em 10.11.2011, que **não**. Ou seja, o STJ escolherá livremente a lista tríplice e poderá incluir juízes dos TRFs ou TJs que ingressaram em referidos tribunais pela regra do quinto constitucional (art. 94 da CF/88). Isso porque, a partir do momento que um advogado ou um membro do MP são investidos no cargo judiciário pela regra do quinto (no TRF ou no TJ), perdem todos os vínculos que anteriormente tinham, passando, então, à **condição de magistrados**, podendo, assim, integrar a lista tríplice. A Constituição, também, não fez qualquer distinção entre magistrados dos tribunais oriundos da carreira ou que chegaram ao tribunal pela regra do quinto;[63](#)

■ **esquematização (processo de escolha): quadro comparativo STF x STJ**

STF (ART. 101)	STJ (ART. 104)	
Composição: 11 Ministros	■ Composição: no mínimo 33 Ministros ■ 1/3 dentre juízes dos TRFs; • 1/3 dentre desembargadores dos TJs	Indicação para escolha: lista tríplice elaborada pelo próprio STJ Indicação para escolha: alternadamente, na forma da regra do “quinto constitucional” — art. 94
■ Escolha e nomeação: Presidente da República	■ Escolha e nomeação: Presidente da República	
■ Sabatina: Senado Federal — aprovação da escolha pela maioria absoluta	■ Sabatina: Senado Federal — aprovação da escolha pela maioria absoluta (EC n. 45/2004)	
■ Requisitos para o cargo I: a) ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade; b) ter notável saber jurídico e	■ Requisitos para o cargo I: a) ter mais de 35 e menos de 65 anos; b) ter notável saber jurídico e reputação ilibada	

reputação ilibada	
■ Requisitos para o cargo II: ser brasileiro nato (art. 12, § 3.º, IV)	■ Requisitos para o cargo II: ser brasileiro nato ou naturalizado

■ **competência do STJ:** a) originária (art. 105, I, “a” até “i”); b) recursal ordinária (art. 105, II); e c) recursal especial (art. 105, III).

Em relação à competência, destacam-se, conforme visto, as novidades introduzidas pela **EC n. 45/2004**, quais sejam:

a) homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias: a competência passou a ser do STJ, tendo sido a matéria regulamentada na **Resolução n. 9, de 04.05.2005/STJ**, até que o *Plenário* da Corte aprove disposições regimentais próprias. Nesse sentido, o art. 960, § 2.º, do CPC/2015 (Novo CPC) estabeleceu que a homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o *RISTJ*. Feito o pedido pelas vias diplomáticas, homologada a sentença ou concedido o *exequatur* pelo STJ, nos termos do art. 109, X, é da competência do **Juiz Federal** a sua **execução**;

b) preservação da competência para o julgamento de **recurso especial** quando a decisão recorrida julgar válido **ato de governo local** contestado em face de **lei federal**. Perfeita a preservação dessa competência já que, nessa hipótese, no fundo, estamos diante de questão de **legalidade**, e não de constitucionalidade.

■ **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):** a **EC n. 45/2004** (art. 105, parágrafo único, I) prescreveu o funcionamento, junto ao STJ, da *Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados*, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o **ingresso** e **promoção** na carreira. A Escola, com autonomia didática, científica, pedagógica, administrativa e

financeira, foi instituída, em **30.11.2006**, por meio da *Resolução n. 3/STJ*, alterada pela *Resolução n. 5/STJ*, de 1.º.07.2008. Nos termos do art. 2.º de referida resolução, destacam-se as seguintes atribuições da Escola: [64](#)

- a)** definir as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de Magistrados;
- b)** fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional;
- c)** promover a cooperação com entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao ensino, pesquisa e extensão;
- d)** incentivar o intercâmbio entre a Justiça brasileira e a de outros países;
- e)** promover, diretamente ou mediante convênio, a realização de cursos relacionados com os objetivos da Enfam, dando ênfase à formação humanística (Resolução n. 5/2008);
- f)** habilitar e fiscalizar, nos termos dos arts. 93, II, “c”, e IV, e 105, parágrafo único, da Constituição da República, os cursos de formação para ingresso na magistratura e, para fins de vitaliciamento e promoção na carreira, os de aperfeiçoamento (Resolução n. 5/2008);
- g)** formular sugestões para aperfeiçoar o ordenamento jurídico;
- h)** definir as diretrizes básicas e os requisitos mínimos para a realização dos concursos públicos de ingresso na magistratura estadual e federal, inclusive regulamentar a realização de exames psicotécnicos (Resolução n. 5/2008). Lembramos que, de acordo com a **SV 44**, “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;
- i)** apoiar, inclusive financeiramente, a participação de magistrados em cursos no Brasil ou no exterior indicados pela Enfam (Resolução n. 5/2008);
- j)** apoiar, inclusive financeiramente, as escolas da magistratura estaduais e federais na realização de cursos de formação e de aperfeiçoamento (Resolução n. 5/2008).

Parágrafo único. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de

Magistrados gozará de autonomia didática, científica e pedagógica, bem como de autonomia administrativa e financeira, observado o disposto no § 2.º do art. 3.º desta resolução (Resolução n. 5/2008).

A **ENFAM** “... ocupa-se com a formação intelectual e moral dos juízes, uma formação que compreenda não apenas o entendimento técnico-jurídico, mas também o conhecimento sociológico, humanístico e prático”. Assim, dentre os seus **objetivos**, destacam-se:

- “a) provocar melhoria na seleção de novos juízes;
- b) promover a atualização constante dos magistrados;
- c) proporcionar formação teórica e prática do operador do Direito;
- d) aproximar ainda mais o Judiciário da realidade do cidadão;
- e) garantir que os magistrados estejam em permanente formação acadêmica e humanística;
- f) cooperar com as escolas federais e estaduais da magistratura no oferecimento e execução de treinamentos e cursos;
- g) contribuir para que todas as escolas da magistratura tenham padronização mínima, respeitando as peculiaridades e necessidades de cada Região;
- h) facilitar a troca de experiências entre as escolas da magistratura e entre os magistrados;
- i) buscar práticas de gestão que permitam a socialização de experiências e de problemas vivenciados pelos magistrados” (cf. <www.enfam.stj.jus.br>).

■ **Conselho da Justiça Federal:** a **EC n. 45/2004** previu, também, o funcionamento, junto ao STJ, do **Conselho da Justiça Federal**, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema e com poderes correccionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

■ 11.8.3. Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Juízes Federais

Organizada em dois graus de jurisdição, a Justiça Federal é composta pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Juízes Federais; sua competência vem

estabelecida nos arts. 108 e 109 da CF/88.

■ **composição dos TRFs:** no mínimo 7 Juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, devendo ser observada a regra do “quinto constitucional” do art. 94;

■ **requisitos para o cargo:** a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) ter mais de 30 e menos de 65 anos de idade.

Em busca da efetividade do processo e do acesso à ordem jurídica justa, a *Reforma do Judiciário* (EC n. 45/2004) previu a instalação da Justiça itinerante e descentralização, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do art. 107:

■ os TRFs instalarão a **Justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários;

■ os TRFs poderão funcionar **descentralizadamente**, constituindo **Câmaras regionais**, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo.

Em relação à **Justiça Federal**, destacamos a federalização de crimes contra direitos humanos, por exemplo, tortura e homicídio praticados por grupos de extermínio, mediante incidente suscitado pelo PGR no STJ objetivando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Busca-se, acima de tudo, adequar o funcionamento do Judiciário brasileiro ao sistema de proteção internacional dos direitos humanos (**art. 109, V-A, e § 5.º**). [65](#)

Finalmente, lembramos que a **EC n. 73/2013** criou os Tribunais Regionais Federais das 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª Regiões, introduzindo o § 11 ao art. 27 do ADCT.

A necessidade de se aumentar por emenda decorre da regra contida no art. 27, § 6.º, do ADCT, que criou, em 1988, os atuais 5 TRFs.

Contra referida emenda, foi ajuizada a **ADI 5.017** pela *Associação Nacional dos Procuradores Federais (ANPAF)* e, em **18.07.2013**, o Min. Joaquim Barbosa concedeu liminar, **suspendendo os seus efeitos** (*pendente de apreciação pelo Pleno* — cf. discussão no item 9.13.3.3.3).

■ 11.8.4. Tribunais e Juízes do Trabalho de acordo com a EC n. 24/99

Como visto, os órgãos da Justiça do Trabalho são o TST, os TRTs e os Juízes do Trabalho, [66](#) sendo sua competência estabelecida no art. 114, abaixo elencada, lembrando a sua ampla reformulação pela [EC n. 45/2004](#).

■ 11.8.4.1. Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Vejamos algumas regras relacionadas ao [TST](#):

■ **composição:** [27](#) Ministros togados e vitalícios (art. 111-A, *caput*, de acordo com a redação dada pela [EC n. 45/2004](#), restabelecendo-se a antiga composição. Como se sabe, a EC n. 24/99 reduziu de 27 para 17 Ministros, acabando com as 10 vagas de Classistas então existentes. A *Reforma do Judiciário* restabelece a composição, deixando de convocar juízes dos TRTs para atuar como substitutos, prática essa condenável);

■ **estrutura da composição:** dos [27](#) Ministros togados e vitalícios, [1/5](#) será escolhido dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; os demais, quais sejam, os [4/5](#) dos 27 Ministros do TST, serão escolhidos dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da [Magistratura da carreira](#), indicados pelo próprio Tribunal Superior.

Em relação ao sistema de composição, percebe-se a nítida redução das vagas de Ministros do TST oriundos da advocacia e Ministério Público do Trabalho. E mais, como o restante das vagas é preenchido por juízes dos TRTs oriundos da [Magistratura da carreira](#), isso significa que juízes dos TRTs que subiram pelo quinto não poderão estar entre esses 4/5 de Ministros do TST, já que, repita-se, o texto fala em juízes dos TRTs *oriundos da Magistratura da carreira*!

■ **requisitos para o cargo:** a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade;

■ **sabatina do Senado Federal:** igualando-se ao STF e STJ, a sabatina

no Senado passa a ser pela **maioria absoluta**, e não mais maioria simples ou relativa, sendo os Ministros nomeados pelo Presidente da República;

■ **competência do TST**: será fixada por lei, nos termos do art. 111-A, § 1.º.

Funcionarão junto ao TST:

■ **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho**, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o **ingresso** e **promoção** na carreira;

■ **Conselho Superior da Justiça do Trabalho**, cabendo-lhe exercer, *na forma da lei*, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Nos termos do art. 6.º da **EC n. 45/2004**, referido Conselho será instalado no prazo de 180 dias, cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regulamentar seu funcionamento por resolução, enquanto não promulgada a referida lei.

■ **11.8.4.2. Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs)**

Vejamos algumas regras relacionadas ao **Tribunal Regional do Trabalho**, consoante o fixado pela *EC n. 45/2004*:

■ **composição**: os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de **30** e menos de **65** anos;

■ **estrutura da composição**: a) **1/5** dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; b) os demais, vale dizer **4/5**, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Em busca da “efetividade do processo” e do “acesso à ordem jurídica justa”, a *Reforma do Judiciário* estabeleceu que os TRTs instalarão a **Justiça**

itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, podendo, ainda, funcionar **descentralizadamente**, constituindo **Câmaras regionais**, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo (art. 115, §§ 1.º e 2.º).

■ **11.8.4.3. Juízes do trabalho — Varas do Trabalho**

Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.

Por fim, lembramos que as Varas do Trabalho serão instituídas por lei, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho (art. 112 da CF/88, na redação determinada pela EC n. 45/2004).

■ **11.8.4.4. Competências da Justiça do Trabalho**

Nos termos do art. 114 da CF/88, introduzido pela EC n. 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- as ações que envolvam exercício do direito de greve;
- as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
- os mandados de segurança, *habeas corpus* e *habeas data*, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
- os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”;
- as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da

relação de trabalho;

- as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
- a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, “a”, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
- outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

O STF já interpretou algumas das novidades introduzidas pela *Reforma do Judiciário*, motivo pelo qual se mostra importante a sua esquematização:

A) A Justiça do Trabalho não é competente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo

Conforme alertamos, a AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil) ajuizou, em 25.01.2005, a **ADI 3.395**, combatendo a nova regra que suprimiu a autonomia da Justiça Federal para julgar ações envolvendo as relações de trabalho dos servidores estatutários. Alegou vício formal no que respeita à tramitação e interpretação conforme.

No julgamento da medida cautelar da ADI 3.395-6, o então Presidente do STF, Ministro Nelson Jobim, concedeu liminar com efeito *ex tunc* para dar interpretação conforme a CF ao inciso I do art. 114, suspendendo, “... ‘ad referendum’, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação trazida pela EC 45/2004, que incluía, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘... apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’”.

Em 05.04.2006, o STF, por maioria, **referendou** a liminar concedida. “Salientou-se, no ponto, a decisão do STF no julgamento da ADI n. 492/DF (*DJU* de 12.03.93), na qual se concluíra pela inconstitucionalidade da inclusão, no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários, **em razão de ser estranho ao conceito de relação de trabalho o vínculo jurídico de natureza estatutária**

existente entre servidores públicos e a Administração” (Inf. 422/STF, DJ de 10.11.2006 — Ata n. 37/2006).

No julgamento da **Rcl 6.568**, em 20.05.2009, o STF novamente confirmou o entendimento fixado na ADI 3.395, ao determinar que a apreciação de greve deflagrada por policiais civis do Estado de São Paulo e que estava sendo apreciada pela Justiça do Trabalho (ato da Vice-Presidente Judicial Regimental do TRT da 2.^a Região, nos autos de dissídio coletivo de greve), deveria ser analisada pelo **Tribunal de Justiça** (*Justiça Comum*).

Dessa forma, o STF reforça a ideia de **afastar** “a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados” por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo (sobre a proibição do exercício de greve por policiais civis e servidores que exercem atividade essencial, cf. *item 13.7.9*).

B) Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho — competência da Justiça do Trabalho

A jurisprudência do STF estabeleceu ser competente a **Justiça do Trabalho** para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador.⁶⁷

Por outro lado, na hipótese de **ações acidentárias** propostas pelo segurado em face do INSS e havendo interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, discutindo controvérsia acerca de benefício previdenciário, a competência é da **Justiça comum estadual**, tendo em vista o critério residual de distribuição de competência (S. 501/STF e art. 109, I, da CF/88).

Resta analisar qual seria o momento para aplicar o novo entendimento do STF, já que, antes da EC n. 45/2004, a posição era outra, qual seja, a competência da Justiça Comum.

Segundo o STF, o marco para fixar a (nova) competência da Justiça do Trabalho (art. 87 do CPC/73 — correspondente ao art. 43, CPC/2015) é a existência ou não de **sentença de mérito**. Havendo sentença de mérito proferida

pela Justiça estadual ou federal (art. 109, I), mesmo sem trânsito em julgado, a competência não será deslocada para a Justiça obreira, por uma questão de **política judiciária**, tendo em vista o significativo número de ações que ainda tramitavam, quando do advento da EC n. 45/2004, na Justiça comum. Nesse sentido:

“Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar pedido de indenização por danos morais e patrimoniais, decorrentes de acidente do trabalho (...). As ações em trâmite na Justiça comum estadual e com **sentença de mérito** anterior à promulgação da EC 45/04 lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não fora apreciado, devem ser remetidas à Justiça laboral, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos já praticados. ‘Consideram-se de interesse público as disposições atinentes à competência em lides contenciosas; por este motivo, aplicam-se imediatamente; atingem as ações em curso. **Excetuam-se os casos de haver pelo menos uma sentença concernente ao mérito**; o *veredictum* firma o direito do Autor no sentido de prosseguir perante a Justiça que tomara, de início, conhecimento da causa’ (Carlos Maximiliano). Precedente plenário: **CC 7.204**. Outros precedentes: RE 461.925-AgR, RE 485.636-AgR, RE 486.966-AgR, RE 502.342-AgR, RE 450.504-AgR, RE 466.696-AgR e RE 495.095-AgR. Agravo regimental desprovido”.⁶⁸

Nessa linha pacificou o **STJ** na **S. 367**: “a competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados” (Corte Especial, j. 19.11.2008, *DJE* de 26.11.2008).

Finalmente, o **STF**, em **02.12.2009**, aprovou a **SV 22**, com o seguinte teor: “a **Justiça do Trabalho** é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, **inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n. 45/04**”.

C) Ação de indenização proposta por viúva e filhos de empregado morto em serviço — Justiça do Trabalho

Em um primeiro momento, o **STJ** firmou o entendimento de que a

competência seria da Justiça Comum Estadual ou Federal por ter a ação natureza civil, chegando, até, a editar a **S. 366** (Corte Especial, j. 19.11.2008, *DJE* de 26.11.2008).

Contudo, o **STF**, ao julgar o **CC 7.545/SC**, em **03.06.2009**, determinou que a competência era da **Justiça do Trabalho**, na medida em que a origem do direito decorreria das relações de trabalho. Nesse sentido:

“EMENTA: (...) A competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, após a edição da EC 45/04, é da Justiça do Trabalho. (...) **O ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a competência da Justiça especializada.** A transferência do direito patrimonial em decorrência do óbito do empregado é irrelevante” (**CC 7.545**, Rel. Min. Eros Grau, j. 03.06.2009, Plenário, *DJE* de 14.08.2009).

Em razão desse novo entendimento proferido pelo STF, em 16.09.2009, no julgamento do CC 101.977-SP, o STJ determinou o **cancelamento** da S. 366, adequando-se, assim, ao novo posicionamento da Suprema Corte, intérprete final da Constituição.

D) A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações penais

“EMENTA: O Tribunal deferiu pedido de liminar formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República para, com efeito *ex tunc*, dar interpretação conforme à Constituição Federal aos incisos I, IV e IX do seu art. 114 no sentido de que neles a Constituição não atribuiu, por si sós, competência criminal genérica à Justiça do Trabalho (...). Entendeu-se que seria incompatível com as garantias constitucionais da legalidade e do juiz natural inferir-se, por meio de interpretação arbitrária e expansiva, competência criminal genérica da Justiça do Trabalho, aos termos do art. 114, I, IV e IX da CF” (ADI 3.684-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, 1.º.02.2007).

Mesmo que se fixe a competência para o julgamento de *habeas corpus*, cabe lembrar que é possível a determinação de prisão civil alimentar por decisão do

juízo trabalhista, motivo pelo qual se prescreveu o remédio para tutelar a liberdade de ir e vir.

E) Segundo o STJ, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação alusiva a relações contratuais de caráter eminentemente civil, diversa da relação de trabalho

Sobre esse tema, a Corte Especial do **STJ** pacificou diversos conflitos de competência nos termos da **S. 363**: “competete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente” (j. 15.10.2008, *DJE* de 03.11.2008). [69](#)

O **STF** ainda não analisou com muita profundidade o assunto. Contudo, no julgamento de ação de cobrança de honorários advocatícios de advogada dativa contra o Estado de Minas Gerais, a Corte, por maioria de votos (vencidos o Min. Marco Aurélio e o Min. Ayres Britto), entendeu como competente a **Justiça estadual comum** (**RE 607.520**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.05.2011, Plenário, *DJE* 21.06.2011, com *repercussão geral*).

F) Ação possessória decorrente do exercício do direito de greve: Justiça do Trabalho

Muitas vezes quando os bancários realizam greve, têm ocorrido o fechamento das agências e a proibição de clientes e mesmo dos trabalhadores de entrarem nos estabelecimentos (“piquete”).

Assim, em razão desses bloqueios, que o próprio movimento grevista vem realizando, alguns bancos propuseram **ações possessórias**, por exemplo, o *interdito proibitório*, em razão, nos termos do art. 932 do CPC/73 (art. 567, CPC/2015), de justo receio de serem molestados na posse (turbação ou esbulho iminente).

A dúvida era saber se a competência seria da Justiça Comum ou do Trabalho. O STF entendeu, partindo do precedente materializado no **CJ 6.959/DF**, [70](#) como competente a Justiça do Trabalho na medida em que, ainda que a solução dependesse da apreciação de questões de direito civil, o seu fundamento decorre da relação trabalhista e, no caso, do exercício do direito de greve, aplicando-se, por consequência, o disposto no art. 114, II, da CF/88.

Nesse sentido, o STF editou a **SV 23**: “a **Justiça do Trabalho** é competente para processar e julgar **ação possessória** ajuizada em **decorrência do exercício do direito de greve** pelos trabalhadores da iniciativa privada”.

G) Súmula Vinculante 53 (j. 18.06.2015)

Após o julgamento do RE 569.056, o STF sedimentou o seguinte entendimento, editando a **SV 53**: “a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados”.

■ 11.8.4.5. O que aconteceu com os mandatos dos classistas em face da EC n. 24/99?

O art. 2.º da referida emenda assegura o cumprimento dos mandatos dos então ministros classistas temporários do TST e dos juízes classistas temporários dos TRTs e das extintas JCJ.

Trata-se de dispositivo perfeitamente condizente com os princípios constitucionais, uma vez que se preservam os direitos já adquiridos dos então (à época da promulgação da EC n. 24/99) classistas, devendo estes continuar a exercer a sua função até o término de seu mandato.

■ 11.8.5. Tribunais e Juízes Eleitorais

Como visto, os órgãos da Justiça Eleitoral são: o **Tribunal Superior Eleitoral** (TSE); os **Tribunais Regionais Eleitorais** (TREs); os **Juízes Eleitorais**; e as **Juntas Eleitorais**.

Cabe lembrar que, como previsto no art. 121, § 2.º, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por **2 anos**, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios **consecutivos**, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

Os membros dos tribunais, os Juízes de Direito e os integrantes das Juntas

Eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de **plenas garantias** e serão **inamovíveis**.

■ **11.8.5.1. Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**

■ **composição:** no mínimo, **7** membros (juízes);

■ **estrutura da composição:** a) **3 juízes** serão eleitos dentre os Ministros do STF, pelo voto secreto, pelos próprios membros da Corte Suprema; b) **2 juízes** serão eleitos, também pelo voto secreto, dentre os Ministros do STJ, pelos próprios Ministros do STJ; c) **2 outros juízes** da seguinte forma: o STF elaborará lista sêxtupla escolhendo nomes dentre **advogados** de notável saber jurídico e idoneidade moral, encaminhando-a ao Presidente da República. Este escolherá **2**, nomeando-os, sem haver a necessidade de sabatina pelo Senado Federal;

■ **Presidente e Vice-Presidente do TSE:** serão eleitos pelo TSE, dentre Ministros do STF;

■ **Corregedor Eleitoral do TSE:** será eleito pelo TSE, dentre Ministros do STJ.

É de ressaltar que as decisões do **TSE** são **irrecorríveis**, **salvo** as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança (art. 121, § 3.º).

■ **11.8.5.2. Tribunal Regional Eleitoral (TRE)**

Conforme dispõe o art. 120 da CF/88, na Capital de cada Estado e no Distrito Federal haverá um Tribunal Regional Eleitoral.

■ **composição:** **7** membros (juízes);

■ **estrutura da composição:** a) eleição, pelo voto secreto, de **2 juízes** dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; b) eleição, pelo voto secreto, de **2 juízes**, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; c) de **1 juiz** do TRF com sede na Capital do Estado ou no Distrito

Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo TRF respectivo; *d*) de **2 juízes**, por nomeação, pelo Presidente da República, dentre **6 advogados** de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça;

■ **Presidente e Vice-Presidente do TRE:** serão eleitos pelo TRE, dentre os desembargadores.

Nos termos do art. 121, § 4.º, das decisões dos TREs somente caberá recurso quando:

- forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou de lei;
- ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
- versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
- denegarem *habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* ou mandado de injunção.

■ **11.8.5.3. Juízes Eleitorais**

Os **Juízes Eleitorais**, consoante o art. 32 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737/65), são os próprios juízes de direito em efetivo exercício e, na falta destes, os seus substitutos legais, da própria organização judiciária do Estado ou do DF, que gozem das prerrogativas do art. 95 da CF/88, cabendo-lhes a jurisdição de cada uma das **zonas eleitorais** em que é dividida a **circunscrição eleitoral** e com as competências expressas no art. 35 do Código Eleitoral (para algumas provas, vale a leitura do referido dispositivo legal. Isso porque certas provas, e aí o candidato atento deve ler os editais, exigem alguns conhecimentos muito específicos!).

Destacamos, por fim, o teor da **S. 368/STJ**: “competete à **Justiça comum esta-**
dual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça

Eleitoral” (1.^a S., j. 26.11.2008, *DJE* de 03.12.2008).

■ 11.8.5.4. Juntas Eleitorais

O art. 121 estatui que lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das **Juntas Eleitorais**.

As regras estão no *Código Eleitoral*, que, dentre outras particularidades, em seu art. 36 estabelece que as **Juntas Eleitorais** compor-se-ão de 1 *juiz de direito*, que será o presidente, e de 2 ou 4 *cidadãos* de notória idoneidade. Os membros das Juntas Eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Outrossim, até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações.

Na dicção do art. 40 do Código Eleitoral, recepcionado como lei complementar e regulador da matéria, compete à Junta Eleitoral: **a)** apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição; **b)** resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração; **c)** expedir os boletins de apuração mencionados no art. 178; **d)** expedir diploma aos eleitos para cargos municipais.

■ 11.8.6. Tribunais e Juízes Militares

Os órgãos da Justiça Militar (*Justiça castrense*), como já visto, previstos no art. 122, I e II, são: o **Superior Tribunal Militar** (STM); os **Tribunais Militares** (TMs) e os **Juízes Militares instituídos por lei**.

Como se sabe, e o tema será retomado em *segurança pública* (cf. *item 13.6*), existem tanto servidores militares federais integrantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica — art. 142, § 3.º) como aqueles militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios, que compõem as Forças Auxiliares e

reserva do Exército (polícia militar e corpo de bombeiro militar — art. 144, § 6.º).

Assim, de maneira coerente, a CF distingue a **Justiça Militar Federal** (da União) de um lado (art. 124) e a **estadual**, também especializada, de outro (art. 125, §§ 3.º, 4.º e 5.º).

■ 11.8.6.1. Superior Tribunal Militar (STM)

Ao **Superior Tribunal Militar**, além de competência originária, foram estabelecidas atribuições para julgar as apelações e os recursos das decisões dos juízes de primeiro grau da Justiça Militar da União (cf. o organograma, *item 11.6.5*).

Deve-se deixar claro que o **STM não examina matérias provenientes da Justiça Militar Estadual ou Distrital**.

Dessa forma, apesar de ter a denominação “Superior Tribunal”, não atua conforme o STJ, já que, no caso, o STM, além das atribuições originárias, funciona como **tribunal recursal** (para bem entendermos, mantidas todas as particularidades, atua como se fosse um TJ).

Tanto é assim que, na **Justiça Militar da União, não existe órgão intermediário entre a primeira instância** (Auditorias) e o **STM** (conforme visto, órgão recursal).

Abaixo indicamos a evolução do STM e, em seguida, regras sobre a composição atual da Corte:

ATO NORMATIVO	DENOMINAÇÃO	NÚMERO DE MEMBROS	TITULAÇÃO
■ Alvará de 1.º.04.1808	■ Conselho do Supremo	■ 15	Conselheiros de Guerra Conselheiros do

(Príncipe-Regente D. João VI)	Militar e de Justiça	■ 15	Almirantado ■ Vogais
■ Dec. n. 149, de 18.07.1893	■ Supremo Tribunal Militar	■ 15	■ Ministros
■ Dec. n. 14.450, de 30.10.1920	■ Supremo Tribunal Militar	■ 9	■ Ministros
■ Decreto-lei n. 925, de 02.12.1938	■ Supremo Tribunal Militar	■ 11	■ Ministros
Constituição de 1946	■ Superior Tribunal Militar	■ 11	■ Ministros
■ AI 2, de 18.09.1946	■ Superior Tribunal Militar	■ 15	■ Ministros
■ CF/88	■ Superior Tribunal Militar	■ 15	■ Ministros

■ **composição:** 15 Ministros vitalícios (art. 123, CF/88);

■ **estrutura da composição:** a) **3** dentre oficiais-generais da Marinha, da ativa e do posto mais elevado da carreira; b) **4** dentre oficiais-generais do Exército, da ativa e do posto mais elevado da carreira; c) **3** dentre oficiais-generais da Aeronáutica, da ativa e do posto mais elevado da carreira; e d) **5** dentre civis, dos quais **3** serão escolhidos dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, **1** dentre juízes auditores e **1** membro do Ministério Público da Justiça Militar;

■ **forma de nomeação:** o Presidente da República aponta a indicação dos 15 Ministros, respeitando-se a proporção acima exposta. A indicação deve

sabatinados. Aprovada a indicação, o Presidente da República os nomeará;

■ **requisitos:** a CF somente prevê, de forma expressa, requisitos para os Ministros civis, quais sejam: *a)* ser brasileiro, nato ou naturalizado; *b)* ter mais de 35 anos de idade; *c)* para os Ministros civis escolhidos dentre os advogados, ter notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional; e *d)* para os oficiais-generais a CF prevê o requisito de serem brasileiros natos, de acordo com o art. 12, § 3.º, VI.

■ **11.8.6.2. Justiça Militar da União**

■ **11.8.6.2.1. Regras gerais e Circunscrições Judiciárias Militares**

Com **competência exclusivamente penal**, incumbe-lhe processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

A Justiça Militar, em nível federal, é constituída, em primeira instância, pelos **Conselhos de Justiça Militar** e, como órgão recursal e de jurisdição superior, pelo **Superior Tribunal Militar** (art. 122 da CF/88). [71](#)

Nos termos do art. 1.º da Lei n. 8.457/92, que *organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares*, são órgãos da Justiça Militar (da União): o **STM**; a **Auditoria de Correição**; os **Conselhos de Justiça**; os **Juizes-Auditores** e os **Juizes-Auditores Substitutos**.

Por sua vez, o art. 2.º da referida Lei n. 8.457/92 estabelece que, para efeito de administração da Justiça Militar **em tempo de paz**, o território nacional divide-se em **12 Circunscrições Judiciárias Militares** (embora estejam sendo feitos estudos para uma **necessária** ampliação dessa divisão em virtude, especialmente, da extensão territorial da *12.ª Circunscrição*) abrangendo:

- **1.ª** — Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo;
- **2.ª** — Estado de São Paulo;
- **3.ª** — Estado do Rio Grande do Sul;

- **3.^a** — Estado do Rio Grande do Sul;
- **4.^a** — Estado de Minas Gerais;
- **5.^a** — Estados do Paraná e Santa Catarina;
- **6.^a** — Estados da Bahia e Sergipe;
- **7.^a** — Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas;
- **8.^a** — Estados do Pará, Amapá e Maranhão;
- **9.^a** — Estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso;
- **10.^a** — Estados do Ceará e Piauí;
- **11.^a** — Distrito Federal e Estados de Goiás e Tocantins;
- **12.^a** — Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

■ **11.8.6.2.2. Conselhos de Justiça Militar**

Nas *Circunscrições Judiciárias Militares* existem as correspondentes **Auditorias** (órgãos de primeira instância da Justiça Militar) que têm **jurisdição mista**, cabendo-lhes conhecer dos feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica.

Conforme vimos, o julgamento em primeira instância nas referidas Auditorias se dá em **colegiado** e por **escabinato**.

Isso porque os julgamentos se implementam nos **Conselhos de Justiça Militar** (colegiado), que são compostos de 1 **juiz togado** (bacharel em direito que ingressou na carreira mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases — art. 93, I, da CF/88) e de **4 juízes leigos** (militares, **sorteados** como se observa abaixo), tendo o valor do voto do togado o mesmo valor do voto dos leigos (escabinato).

Essa composição plúrima por juiz togado e juízes leigos (militares) se justifica em razão da necessidade de se harmonizarem os conhecimentos técnicos com a experiência da caserna, tendo como pano de fundo a ideia de **hierarquia** e

Os **Conselhos** se dividem em duas espécies, o **Especial** e o **Permanente**, e funcionarão na **sede** das **Auditorias**, salvo casos especiais por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da Justiça e pelo tempo indispensável, mediante deliberação do Superior Tribunal Militar.

O **Conselho Especial de Justiça** é constituído pelo **juiz-auditor** e **4 juizes militares**, sob a presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais juizes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade.

Por sua vez, o **Conselho Permanente de Justiça** é constituído pelo **juiz-auditor**, por **1 oficial superior**, que será o presidente, e **3 oficiais** de posto até **capitão-tenente** ou **capitão**.

Para efeito de **composição dos Conselhos**, nas respectivas Circunscrições, os comandantes de *Distrito* ou *Comando Naval*, *Região Militar* e *Comando Aéreo Regional* organizarão, trimestralmente, relação de todos os oficiais em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, publicando-a em boletim e remetendo-a ao juiz-auditor competente para que, então, se proceda, nos termos dos arts. 19 a 22 da Lei n. 8.457/92, ao **sorteio**.

O **Conselho Especial** (art. 23 da Lei n. 8.457/92) é **constituído para cada processo** e **dissolvido** após a **conclusão dos seus trabalhos**, reunindo-se, novamente, se sobrevier nulidade do processo ou do julgamento, ou diligência determinada pela instância superior, sendo que os juizes militares que o integrarem serão de **posto superior** ao do **acusado**, ou do **mesmo posto e de maior antiguidade**.

Quanto ao **Conselho Permanente** (art. 24 da Lei n. 8.457/92), uma vez constituído, embora o nome “permanente”, funcionará durante **três meses consecutivos**, *coincidindo com os trimestres do ano civil*, podendo o prazo de sua jurisdição ser prorrogado nos casos previstos em lei. O oficial que tiver integrado o Conselho Permanente não será sorteado para o trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver insuficiência de oficiais.

O quadro a seguir ajuda a entender a distinção entre os Conselhos:

	CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA	CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
CONSTITUIÇÃO	■ Juiz Auditor ■ 4 Juízes Militares de posto superior ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade	■ Juiz Auditor ■ 1 Oficial Superior ■ 3 Oficiais de posto até Capitão-Tenente ou Capitão
DURAÇÃO/ FUNCIONAMENTO	■ constituído para cada processo e dissolvido após a conclusão dos trabalhos	■ 3 meses consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil ■ possibilidade de prorrogação de prazo nos casos previstos em lei
COMPETÊNCIA	■ processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação penal militar ■ a competência para processar e julgar os oficiais-generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos é, de acordo com o art. 6.º, I, “a”, da Lei n. 8.457/92, originária do STM	■ processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos previstos na legislação penal militar, como as praças e, nas hipóteses admitidas pela lei, os civis ■ CUIDADO: os civis, nas hipóteses previstas em lei, poderão ser julgados apenas pela <i>Justiça Militar da União</i> e jamais

	■ crimes praticados em coautoria com oficiais, mesmo que por não oficiais, serão processados e julgados pelo Conselho Especial de Justiça	serão julgados pela <i>Justiça Militar Estadual</i>, que, em razão de sua competência constitucional, só julga militares
--	---	---

■ 11.8.6.2.3. Hierarquia militar (postos e graduações)

A **hierarquia** e a **disciplina** são a base institucional das **Forças Armadas**, sendo que a autoridade e a responsabilidade são proporcionais ao grau hierárquico, isto é, quanto mais elevado este, maiores serão aquelas.

A **hierarquia militar** é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por **postos** ou **graduações** e, dentro de um mesmo posto ou graduação, pela **antiguidade** (no posto ou na graduação):

■ **posto**: é o grau hierárquico do **oficial**, conferido por ato do Presidente da República ou do Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica e confirmado em Carta Patente.

■ **graduação**: é o grau hierárquico da **praça**, conferido pela autoridade militar competente.

Já a **disciplina** é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

A seguir, para conhecimento, reproduzimos os **postos** e **graduações** das Forças Armadas, para que se compreendam, com precisão, as competências dos **Conselhos Especial e Permanente de Justiça**. Cabe alertar que os postos de

Almirante, Marechal e Marechal do Ar serão providos **somente** em **tempo de guerra**:[72](#) [73](#)

	MARINHA	EXÉRCITO	AERONÁUTICA
OFICIAIS- -GENERAIS	■ Almirante	■ Marechal	■ Marechal do Ar
	■ Almirante de Esquadra	■ General de Exército	■ Tenente-brigadeiro
	■ Vice-almirante	■ General de Divisão	■ Major-brigadeiro
	■ Contra-almirante	■ General de Brigada	■ Brigadeiro
OFICIAIS SUPERIORES	■ Capitão de Mar e Guerra	■ Coronel	■ Coronel
	■ Capitão de Fragata	■ Tenente-coronel	■ Tenente-coronel
	■ Capitão de Corveta	■ Major	■ Major
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS	■ Capitão-tenente	■ Capitão	■ Capitão
OFICIAIS SUBALTERNOS	■ 1.º Tenente	■ 1.º Tenente	■ 1.º Tenente
	■ 2.º Tenente	■ 2.º Tenente	■ 2.º Tenente

PRAÇAS ESPECIAIS ⁷³	■ Guarda- marinha	■ Aspirante a Oficial	■ Aspirante a Oficial
	■ Aspirantes (alunos da Escola Naval)	■ Cadetes (alunos da Academia Militar das Agulhas Negras — AMAN)	■ Cadetes (alunos da Academia da Força Aérea — AFA) e alunos do Curso de Formação de Oficiais Especialistas — CFOE
	■ Suboficial	Subtenente	■ Suboficial
	■ 1.º Sargento	■ 1.º Sargento	■ 1.º Sargento
	■ 2.º Sargento	■ 2.º Sargento	■ 2.º Sargento
	■ Aluno (Colégio Naval) (Praças Especiais) ⁷⁴	■ Aluno (Escola Preparatória de Cadetes do Exército — EsPCEx) (Praças Especiais)	■ Aluno (Escola Preparatória de Cadetes do Ar — EPCAR) (Praças Especiais)
	■ 3.º Sargento	■ 3.º Sargento	■ 3.º Sargento
	■ Aluno (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante	■ Aluno (Centro de Preparação de Oficiais da	■ Aluno (Centro de Preparação de Oficiais

(PRAÇAS)	— EFOMM) (Praças Especiais) ⁷⁵	Reserva CPOR) (Praças Especiais)	ITA) (Praças Especiais)
	■ Cabo	■ Cabo e Taifeiro-mor	■ Cabo e Taifeiro-mor
	■ Alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos (Praças Especiais)	■ Alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos (Praças Especiais)	■ Alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos (Praças Especiais)
	■ Marinheiro e Soldado Fuzileiro Naval	■ Soldado e Taifeiro de 1. ^a Classe	■ Soldado e Taifeiro de 1. ^a Classe
	■ Marinheiro Recruta e Soldado Fuzileiro Naval Recruta	■ Soldado e Taifeiro de 2. ^a Classe	■ Soldado e Taifeiro de 2. ^a Classe

■ 11.8.6.2.4. Ministério Público Militar e Defensoria Pública da União [74](#) [75](#)

Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública da União [76](#) mantêm **representantes** junto à Justiça Militar.

Como vimos, o Ministério Público da União compreende, dentre outros, o **Ministério Público Militar** (art. 128, I, “c”). Trata-se de carreira própria e com concurso público específico.

■ 11.8.6.2.5. A Justiça Militar da União julga civil?

Cabe observar importante diferenciação. Conforme veremos a seguir, a **Justiça Militar Estadual não julga civil**, mas somente *policia militar* e *bombeiro militar* (regra expressa do art. 125, §§ 3.º, 4.º e 5.º).⁷⁷

Contudo, a **Justiça Militar da União**, que julga os militares integrantes das Forças Armadas, em certos casos, também poderá julgar o **civil**.

De acordo com o art. 9.º, III, do Código Penal Militar (Decreto-lei n. 1.001/69), consideram-se crimes militares, **em tempo de paz**, os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por **civil**, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como também os do inciso II, nos seguintes casos:

- contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
- em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
- contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
- ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior.

Nesse sentido: “Considerando que compete à Justiça Militar (da União, acrescente-se) o julgamento de crime cometido por civil em face de patrimônio pertencente à União que está sob a administração militar (CPM, art. 9.º, III, *a*), a Turma negou provimento a recurso em *habeas corpus* no qual se pretendia ver declarada a competência da justiça comum para julgamento da espécie — consistente no suposto superfaturamento de serviços por médico civil, em

decorrência de contrato de prestação de serviços firmado com a Marinha —, sob alegação de que não se teria atingido o patrimônio direcionado às atividades militares próprias. Precedente citado: HC 79.792-PA (DJU de 03.03.2000). RHC 81.048-PE, Rel. Min. Moreira Alves, 7.8.2001 (RHC-81048)” [\(Inf. 236/STF\)](#). [78](#)

■ 11.8.6.2.6. E os crimes dolosos contra a vida?

O art. 124 da CF/88 dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar **os crimes militares definidos em lei**, qual seja, no caso, o *Código Penal Militar*.

Assim, se o crime doloso contra a vida for praticado por um **militar** contra outro **militar**, a competência para julgamento, fixada na lei (art. 9.º), será da **Justiça Militar**.

E se a vítima for **civil**?

Nesse caso, devemos encontrar a resposta na **lei**.

Isso porque a Constituição não definiu qualquer regra. Apenas estabeleceu (art. 124) que a competência será definida na lei, no caso, no *Código Penal Militar (CPM)*.

Antes de responder, observamos que, para a **Justiça Militar Estadual**, no entanto, há regra explícita: a competência é do Tribunal do Júri se a vítima for civil (art. 125, § 4.º, da CF/88).

Para a **Justiça Militar da União**, o art. 9.º, parágrafo único, do CPM estabelece que os crimes de que trata este artigo, quando **dolosos contra a vida** e cometidos contra **civil**, serão, por regra, da competência da **justiça comum**, qual seja, do Tribunal do Júri.

Mas **CUIDADO**: referido dispositivo foi alterado pela **Lei n. 12.432/2011**, que excepcionou a regra geral e determinou que a competência será da **Justiça Militar**, *mesmo na hipótese de crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil*, **quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei n. 7.565, de 19.12.1986 — Código Brasileiro de Aeronáutica**

(CBA).

O art. 289 do CBA estatui que, na infração aos preceitos do Código ou da legislação complementar, a **autoridade aeronáutica** poderá tomar, dentre várias providências administrativas, as de **detenção**, interdição ou apreensão de aeronave, ou do material transportado, e o art. 303 do CBA estabelece que a **aeronave** poderá ser **detida** pelas autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal, nas seguintes hipóteses:

- se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos internacionais, ou das autorizações para tal fim;
- se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional;
- para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis;
- para verificação de sua carga no caso de restrição legal (art. 21) ou de porte proibido de equipamento (parágrafo único do art. 21);
- para averiguação de ilícito.

Nessas hipóteses, a autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe for indicado.

Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como **hostil**, ficando sujeita à **medida de destruição**, após autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada, qual seja, nos termos do art. 10 do Dec. n. 5.144/2004, o *Comandante da Aeronáutica*.

O art. 5.º, do referido decreto, estabelece que a **medida de destruição** consiste no **disparo de tiros**, feitos pela aeronave de interceptação, com a finalidade de provocar danos e impedir o prosseguimento do voo da aeronave **hostil**, e somente poderá ser utilizada como **último recurso** e após o **cumprimento de todos os procedimentos que previnam a perda de vidas inocentes**, no ar ou em terra.

Essa possibilidade de destruição da aeronave e, assim, como decorrência da

medida, a eventual **morte de civis** que estejam a bordo são normas que foram introduzidas pela **Lei n. 9.614/98**, conhecida como “**Lei do Abate**”, havendo ampla regulamentação no citado Dec. n. 5.144/2004.

Naturalmente, a autoridade responderá por seus atos quando agir com **excesso** ou **abuso de poder** ou com **espírito emulatório**, e, assim, nessas circunstâncias, caracterizado eventual crime doloso contra a vida (no caso, por exemplo, a morte dos tripulantes da aeronave supostamente considerada hostil), a competência para julgamento do militar não será da justiça comum (apesar de civil a vítima), mas da **Justiça Militar**.

Portanto, muito **cuidado** nos termos expostos, **quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei n. 7.565/86 (CBA)**, a Justiça Militar da União será competente para julgar suposto crime doloso contra a vida praticado contra civil.

■ **11.8.6.2.7. A Lei n. 9.099/95 (que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências) se aplica no âmbito da Justiça Militar?**

De acordo com o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, incluído pela Lei n. 9.839/99, as disposições contidas na *Lei dos Juizados Especiais* não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

Esse entendimento foi **confirmado** pelo STF no julgamento do **HC 99.743** (j. 06.10.2011), no qual se discutia a aplicação do art. 88, II, “a”, do *Código Penal Militar*, que exclui a *suspensão condicional da pena* em relação a diversos crimes, como, no caso em análise, o **crime de deserção**, bem como a impossibilidade de serem aplicadas regras mais benéficas da *Lei dos Juizados Especiais*, como a do “*sursis* processual” (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Apesar da fixação desse entendimento no sentido da constitucionalidade de referida exclusão em relação aos militares, restou em aberto se ela se aplica também quando o réu for um **civil**.

Assim, essa discussão se resume à **Justiça Militar da União**, já que,

conforme visto, a Justiça Militar Estadual não julga civis.

Em **nosso entender**, o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 **não se aplica na hipótese de crime militar cometido, em tempo de paz, por civil**. Ou seja, a regra de afastamento da Lei dos Juizados Especiais só se aplica se o crime for praticado por **militar**.

Isso porque os civis, entendemos, apesar de poderem ser julgados pela Justiça Militar da União, **não** estão sujeitos aos **valores da hierarquia e disciplina** (art. 142 da CF/88) e, pois, devem ter direito às **normas penais mais benéficas** previstas na Lei n. 9.099/95.

CUIDADO: o tema ainda não foi analisado pelo STF, que, no HC 99.743 citado, estabeleceu, sem qualquer dúvida, a constitucionalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, e, assim, a não aplicação das disposições contidas na *Lei dos Juizados* no âmbito da Justiça Militar quando o crime for praticado por militar (a situação concreta dos autos). Os Ministros Luiz Fux, Ayres Britto e Celso de Mello declararam, em *obiter dictum*, que, se o réu fosse civil, a regra restritiva não deveria ser aplicada (**matéria pendente**).

■ 11.8.6.2.8. A Justiça Militar da União e a Reforma do Judiciário

Em relação à primeira etapa da *Reforma do Judiciário*, aprovada como EC n. 45/2004, cabe observar que **nada foi modificado no tocante à estrutura da Justiça Militar da União**.

A *PEC n. 29-A (358/05-CD)*, contudo, que voltou para a CD e ainda precisa ser apreciada (“*PEC Paralela do Judiciário*”), nos mesmos termos da EC n. 45/2004 (art. 125, § 5.º — julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares dos militares **estaduais**), também, **se aprovada**, ampliará a competência da Justiça Militar da **União** para o julgamento de matéria de natureza disciplinar.

Dessa forma, se em provas de concurso perguntarem se a Justiça Militar da União julga matéria não militar (civil ou disciplinar), até o presente momento, a resposta deverá ser **negativa**, já que, enfatize-se, a competência para o julgamento de matéria civil, nas hipóteses elencadas, está restrita à Justiça Militar

Estadual e à do DF, por força da novidade trazida pela *Reforma do Judiciário* (EC n. 45/2004). No caso dos Militares das Forças Armadas, em se tratando de matéria *não militar*, a competência continua sendo da **Justiça Federal**.

■ 11.8.6.3. *Justiça Militar dos Estados*

■ 11.8.6.3.1. *Atribuições*

Compete à Justiça Militar dos Estados, que poderá ser criada por lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, processar e julgar os **militares** dos Estados, nos **crimes militares** definidos em lei, e as **ações judiciais** contra atos **disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil**, cabendo ao **tribunal** competente decidir sobre a **perda do posto** e da **patente** dos **oficiais** e da **graduação** das **praças** (art. 125, § 4.º).

Diante dessa regra, percebe-se que a Justiça Militar Estadual não julga civil, já que lhe compete “processar e julgar os **militares**...”.

Daí, se um civil praticar o crime de furto em um quartel da Polícia Militar do **Estado**, ele será processado e julgado pela **Justiça comum** e com fundamento no CP e no CPP.

E, então, qual foi a grande novidade trazida pela **EC n. 45/2004**?

Conforme vimos, pela primeira vez, a Justiça Militar dos Estados passa a poder julgar **ato disciplinar**, matéria essa anteriormente afeta às Varas da Fazenda Pública.

Como assinalou Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, “a definição de ato disciplinar ensejará várias discussões doutrinárias e jurisprudenciais, mas a princípio poderá ser entendido como sendo o ato administrativo por meio do qual a Administração Pública Militar impõe uma sanção ao militar infrator, que foi acusado da prática de uma transgressão disciplinar, contravenção disciplinar, de natureza leve, média, ou grave, prevista no Regulamento Disciplinar, ou no Código de Ética e Disciplina”.[79](#)

E se o crime praticado for de competência do júri?

Se a **vítima** for **civil**, a competência será do **júri popular**. No entanto, se a vítima for militar, o crime doloso contra a vida, praticado por outro militar estadual, continua sendo da Justiça Militar.

Dessa maneira, a controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei n. 9.299/96, que alterou o art. 9.º do CPM e o art. 82 do CPPM, fixando a competência da Justiça comum, ao menos em relação aos militares estaduais, está resolvida.

E, nessa hipótese, qual o processamento?

Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, em interessante observação, destaca que “os militares estaduais serão denunciados em caso de indícios de autoria e materialidade pelo promotor de justiça que atua perante o Tribunal do Júri. É importante observar que *a Emenda Constitucional confirmou a competência da Justiça Comum, mas não alterou as disposições da Lei Federal n. 9.299/1996, que determina que o Inquérito Policial que apura a prática do crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil é o Inquérito Policial Militar — IPM*. Assim, concluído o IPM este deverá ser remetido à Justiça Militar, para ser distribuído a um dos promotores de justiça que atua perante aquela Justiça Especializada. Após a manifestação do promotor, caberá ao juiz-auditor remeter os autos à Justiça Comum, Vara do Júri, para que o acusado seja processado e julgado na forma das disposições do Código de Processo Penal”. [80](#)

■ 11.8.6.3.2. Composição e competência

Em relação à **composição** da Justiça Militar Estadual, a **EC n. 45/2004** estabeleceu no art. 125, § 3.º, da CF/88, que a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos **juízes de direito** e pelos **Conselhos de Justiça** e, em segundo grau, pelo próprio **Tribunal de Justiça (TJ)**, ou por **Tribunal de Justiça Militar (TJM)** nos Estados em que o efetivo militar seja **superior a 20 mil integrantes** (como em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul).

Do acórdão da decisão do TJM ou TJ caberá recurso para o STJ ou STF, ou

para ambos, a depender da matéria. Deve-se deixar bem claro, então, que o STM (Superior Tribunal Militar) não aprecia matéria proveniente da Justiça Militar Estadual, restringindo-se à Justiça Militar Federal.

Percebe-se, assim, que, muito embora mantido o *escabinato* (colegiado formado por juízes togados e leigos com valor de voto igual para todos), materializando verdadeiro juízo hierárquico, há a possibilidade de **juízo monocrático** na Justiça Militar Estadual.

O § 5.º do art. 125, introduzido pela EC n. 45/2004, dispõe que compete aos **juízes de direito** do juízo militar processar e julgar, **singularmente**, os **crimes militares cometidos contra civis** e as **ações judiciais contra atos disciplinares militares**, cabendo ao **Conselho de Justiça**, sob a **presidência de juiz de direito**, processar e julgar os demais crimes militares.

Ao **Conselho de Justiça Permanente** compete processar e julgar as **Praças** (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) e **Praças Especiais** (Aspirante a Oficial e Aluno Oficial) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar nos crimes militares definidos em lei, enquanto ao **Conselho de Justiça Especial**, os **Oficiais** (tenentes, capitães, maiores, tenentes-coronéis e coronéis) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar nos delitos previstos na legislação penal militar.

Roberto Botelho observa que mesmo antes da Reforma, que fixou a presidência dos Conselhos para o juiz de direito, “... desde aquela época, todas as coletas de oitivas das partes já eram materializadas pelo juiz de direito togado...”.⁸¹

Assim, o **juiz de direito do juízo militar estadual** julgará, singularmente, todo *crime militar cometido (pelo militar)* contra civil, **exceto o crime doloso contra a vida**, já que, nos termos do art. 125, § 4.º, fica ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, e, como novidade e já estudado, julgará, também, os atos disciplinares *praticados pelos militares*.

CUIDADO: em relação à Justiça Militar da União, essa competência continua afeta ao Conselho de Justiça (Especial ou Permanente), não tendo sido atribuída a juiz-auditor⁸² pela EC n. 45/2004, embora a previsão na *PEC*

Paralela da Reforma do Judiciário ainda esteja pendente de apreciação pelo Congresso Nacional.

Nesses casos de *crimes militares cometidos contra civil* (com a ressalva dos crimes dolosos contra vida), “os militares integrantes dos Conselhos, Especial ou Permanente, não poderão participar dos atos instrutórios. A matéria será analisada exclusivamente pelo Juiz, independentemente do grau hierárquico do militar acusado, praça ou oficial. A competência em atendimento a norma constitucional não mais se estabelece pelo posto ou graduação do agente, mas em razão da vítima ser um civil e suportar uma infração penal em tese praticada por um militar”. [83](#)

Os demais crimes militares definidos em lei serão julgados pelo **Conselho de Justiça**, que, formado pelo **juiz togado** e por **4 juízes militares**, oficiais, sorteados e temporários para o exercício da função específica, será por aquele (**juiz de direito**) presidido.

Finalmente, como já referido, na Justiça Militar Estadual, o órgão recursal é o TJ ou TJM (onde houver), com atribuições também originárias, nos termos da lei.

Destacamos a previsão contida no art. 125, § 4.º, da CF/88, que estabelece ser atribuição do **tribunal competente** decidir sobre a **perda** do **posto** e da **patente** dos **oficiais** e da **graduação** das **praças**, remetendo para a discussão no item seguinte.

Por todo o exposto, podemos resumir:

- a Justiça Militar Estadual **não julga civil**, em nenhuma hipótese;
- crime militar definido em lei praticado por militar estadual contra militar — julgamento pela Justiça Militar — *Conselho de Justiça Especial ou Permanente*, sob a presidência do juiz de direito;
- crime militar definido em lei praticado por militar estadual contra civil — Justiça Militar (*juiz de direito*, e não o Conselho — *vide* art. 125, § 5.º), ressalvada a competência do júri popular (se a vítima for civil);
- crime doloso contra a vida praticado por militar contra militar — a

competência para processar e julgar é do Conselho de Justiça, presidido pelo juiz de direito da Justiça Militar Estadual;

■ o órgão recursal que aprecia a decisão da primeira instância (Auditorias Militares Estaduais), além de possuir competência originária, é o **TJ** ou o **TJM** (onde houver), e não o STM.

■ **11.8.6.3.3. Aplicação da pena de perda do posto e da patente (oficiais) e da graduação (praças): atribuição exclusiva do Tribunal competente ou possibilidade de ser imposta como pena acessória?**

O art. 102 do *Código Penal Militar (CPM)* estatui que a condenação da **praça** a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 anos, importa sua **exclusão** das Forças Armadas.

A grande questão que precisamos enfrentar é saber se a perda do **posto** (Oficiais) e da **graduação** (Praças) dos **militares estaduais** depende ou não de **procedimento específico** perante o **Tribunal** competente, ou se pode ser aplicada como pena acessória nos termos do art. 102 do CPM.

Inicialmente, devemos confrontar o dispositivo indicado com o art. 125, § 4.º, da CF/88, e o art. 142, § 3.º, VI e VII. Vejamos:

Art. 102 do CPM	Art. 125, § 4.º, da CF/88	Art. 142, § 3.º, VI e VII, da CF/88
■ “a condenação da praça a pena privativa de liberdade,	■ “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos	■ “o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível , por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em

de liberdade, por tempo superior a 2 anos, importa sua exclusão das Forças Armadas”	disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças ”	tempo de guerra” ■ “o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos , por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior”
---	---	---

A regra do art. 142, § 3.º, VI e VII, exige **procedimento especial** e **autônomo** por **Tribunal Militar competente** para o reconhecimento da perda do **posto** e da **patente** do **Oficial** que for julgado **indigno do oficialato ou com ele incompatível**.

Ao que se observa, a regra se aplica apenas aos **oficiais**, na medida em que as praças têm graduação, e não posto.

Essa regra se aplica apenas aos Oficiais das Forças Armadas ou deve ser estendida também para os oficiais militares estaduais?

O art. 142, § 3.º, VI e VII, traz regras sobre as Forças Armadas, mas, por força do art. 42, também se aplica aos militares estaduais.

Portanto, a regra de necessidade de decisão de **Tribunal Militar** competente em **processo específico** deve ser estendida também aos **oficiais militares estaduais**.

E como fica a situação das **praças estaduais**?

Como o texto do art. 142, § 3.º, VI e VII, direciona-se apenas aos **oficiais**, tendo em vista que esse dispositivo é aplicado aos **oficiais** militares estaduais, por força do art. 42 da CF/88, para as **praças estaduais** valeria a regra do art. 102 do CPM, e, assim, a exigência de procedimento específico para declaração da perda de cargo por Tribunal Militar não teria de ser observada.

Esse entendimento foi confirmado pelo STF no julgamento do **RE 447.859** (j. 21.05.2015), por “placar” bastante apertado (6 x 5).

Em sentido contrário, contudo, os Ministros vencidos sustentavam que “a **perda de graduação das praças das polícias militares** deve ser **declarada** pelo **tribunal competente** — ou o Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar onde houver — mediante procedimento específico” (*Notícias STF*, 04.06.2009).

Concordamos com esse entendimento, vencido, que não prevaleceu no STF, especialmente diante da regra explícita do art. 125, § 4.º, da CF/88, que estabelece ser competência do **tribunal competente** decidir sobre a **perda** do **posto** e da **patente** dos **oficiais** e da **graduação** das **praças**. Em nosso entender, essa regra específica (que iguala oficiais e praças no âmbito estadual) afastaria a regra geral do art. 142, § 3.º (que trata apenas de oficiais para o caso das Forças Armadas).

Resumindo:

■ **Oficiais das Forças Armadas** (Marinha, Exército e Aeronáutica): o **oficial** só perderá o **posto** e a **patente** se for julgado **indigno do oficialato ou com ele incompatível**, por decisão de **tribunal militar**, exigindo-se **procedimento específico**, não podendo ser aplicada a perda como pena acessória;

■ **Praças das Forças Armadas** (Marinha, Exército e Aeronáutica): como a indicação de procedimento específico só se direciona aos oficiais (art. 142, § 3.º, VI e VII), essa exigência da necessidade de decisão por **tribunal militar** não se aplica às praças das Forças Armadas;

■ **Militares Estaduais** (PM e Corpo de Bombeiros), **oficiais** ou **praças**: em nosso entender, aplica-se, para ambos, o art. 125, § 4.º, da CF/88, que exige um procedimento específico, perante **Tribunal Militar** competente, devendo ser afastado o art. 102 do CPM (nesse sentido, existem precedentes do STF).⁸⁴ **CONTUDO**, conforme informado, esse entendimento não prevaleceu no julgamento do RE 447.859, tendo o STF firmado a interpretação no sentido de se exigir o processo específico **apenas** para os **oficiais** militares estaduais. Assim, às praças se aplica o

art. 102 do CPM.⁸⁵

■ **11.8.6.3.4. Hierarquia militar estadual (postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar)** [85](#)

Conforme visto, a **hierarquia** e a **disciplina** também são a base institucional dos **Militares Estaduais** (PM e Corpo de Bombeiros), sendo que a autoridade e a responsabilidade também aqui estão relacionadas com o grau hierárquico.

A **ordenação** se faz por **postos** (oficiais) ou **graduações** (praças) e, dentro de um mesmo posto ou graduação, pela **antiguidade** (no posto ou na graduação).

Os graus hierárquicos seguem, com algumas particularidades, os do Exército. Não se fala em oficiais gerais, **não existindo**, assim, no âmbito dos militares estaduais, *General* e *Marechal*. Abaixo reproduzimos quadro para conhecimento:[86](#)[87](#)

	POLÍCIAMILITAR	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
OFICIAIS SUPERIORES	■ Coronel PM	■ Coronel BM
	■ Tenente-coronel PM	■ Tenente-coronel BM
	■ Major PM	■ Major BM
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS	■ Capitão PM	■ Capitão BM
OFICIAIS SUBALTERNOS	■ 1.º Tenente PM	■ 1.º Tenente BM

	■ 2.º Tenente PM	■ 2.º Tenente BM
PRAÇAS ESPECIAIS	■ Aspirante a Oficial PM	■ Aspirante a Oficial BM
	■ Aluno Oficial PM87	■ Aluno Oficial BM
GRADUADOS (PRAÇAS)	■ Subtenente PM	■ Subtenente BM
	■ 1.º Sargento PM	■ 1.º Sargento BM
	■ 2.º Sargento PM	■ 2.º Sargento BM
	■ 3.º Sargento PM	■ 3.º Sargento BM
	■ Cabo PM	■ Cabo BM
	■ Soldado PM	■ Soldado BM

■ 11.8.6.3.5. Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual (Justiça Militar Estadual)

Vale observar que tanto o Ministério Público Estadual como a Defensoria Pública Estadual mantêm **representantes** junto à Justiça Militar Estadual.

CUIDADO: em relação ao Ministério Público, contudo, apesar de no âmbito **federal** existir uma carreira própria para atuação perante a **Justiça Militar da União** — o **MPM** (art. 128, I, “c”) —, no âmbito **estadual**, seja em primeiro grau (**Auditorias Militares**, que correspondem às Varas na Justiça Comum), seja até mesmo no TJ ou TJM onde houver (SP, MG e RS — art. 125, § 3.º, da CF/88), a atuação dar-se-á por um membro do **MP Estadual**, **não** havendo uma

carreira própria e específica de *Ministério Público Militar Estadual*. Trata-se de *Promotoria de Justiça especializada com atuação perante a Auditoria Militar* e o *TJ* ou *TJM* onde houver (SP, MG e RS).

■ 11.8.6.4. *Justiça Militar do Distrito Federal*

Na mesma linha das regras para os Estados-Membros, o art. 36 da Lei n. 11.697/2008 estabelece que a **Justiça Militar do Distrito Federal** será exercida pelo **TJ** em segundo grau e, em primeiro grau, pelo **Juiz de Direito do Juízo Militar** e pelos **Conselhos de Justiça** (*Conselho Permanente de Justiça*, para processar e julgar as *Praças e Praças Especiais*, e *Conselho Especial de Justiça*, para processar e julgar os *Oficiais*), tendo por competência o processo e o julgamento dos crimes militares, definidos em lei, praticados por Oficiais, Praças e Praças Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Em nosso entender, embora a EC n. 45/2004 tenha se referido (em relação às novidades) somente à Justiça Militar Estadual, as regras apresentadas também valerão para a Justiça Militar do DF, apesar de organizada e mantida pela União.

■ 11.8.7. *Tribunais e Juízes dos Estados*

Residualmente, compete à Justiça Estadual tudo o que não for de competência das Justiças especiais ou especializadas, nem da Justiça Federal.

Para se ter um exemplo, o STF editou a **SV 27/2009** (*DJE* de 23.12.2009): “compete à **Justiça estadual** julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, **quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem oponente**”, não se caracterizando, portanto, a regra contida no art. 109, I.

Organiza-se em dois graus de jurisdição (“instâncias”), sendo o **primeiro**, em regra, monocrático, ou seja, o julgamento é realizado por um só juiz (**exceções:** a) Juntas Eleitorais, b) Tribunal do Júri, c) Conselhos de Justiça Militares, d)

processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, de acordo com a decisão do juiz — Lei n. 12.694/2012 etc.), [88](#) e o **segundo**, normalmente, por órgãos colegiados (veja, contudo, a regra do art. 34 da Lei n. 6.830/80, admitindo, além de embargos de declaração, os “embargos infringentes” em face das decisões proferidas nas execuções fiscais de até 50 ORTN, para *o mesmo juízo singular prolator da decisão*. Lembrar a possibilidade de cabimento de recurso extraordinário contra a aludida decisão que julga os embargos infringentes, desde que esgotada a instância ordinária, nos termos da **S. 640/STF** e *leading case* no RE 136.154-9).

Em relação ao julgamento em primeira instância, destaca-se a Lei Estadual de Alagoas n. 6.806/2007, que criou a 17.^a Vara Criminal da Capital, com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados pelo crime organizado naquele Estado, e que terá titularidade **coletiva**, sendo composta por 5 Juízes de Direito.

O STF, no julgamento da **ADI 4.414**, em 31.05.2012, entendeu como **constitucional** a previsão colegiada. “Articulou-se possível que lei estadual instituisse órgão jurisdicional colegiado em 1.^o grau. Rememoraram-se exemplos equivalentes, como Tribunal do Júri, Junta Eleitoral e Turma Recursal. Analisou-se que a composição de órgão jurisdicional inserir-se-ia na **competência legislativa concorrente** para versar sobre **procedimentos em matéria processual** (CF, art. 24, XI). Assim, quando a norma criasse órgão jurisdicional colegiado, isso significaria que determinados atos processuais seriam praticados mediante a chancela de mais de um magistrado, **questão meramente procedimental**. Avaliou-se que a lei estadual teria atuado em face de omissão de lei federal, relativamente ao dever de preservar a independência do juiz na persecução penal de crimes a envolver organizações criminosas. Observou-se que o capítulo do CPP referente à figura do magistrado não seria suficiente para cumprir, em sua inteireza, o mandamento constitucional do juiz natural (CF, art. 5.^o, XXXVII e LIII), porque as organizações criminosas representariam empecilho à independência judicial, na forma de ameaças e outros tipos de molestamentos voltados a obstaculizar e desmoralizar a justiça. A corroborar

essa tese, citou-se o *II Pacto Republicano de Estado*, assinado em 2009, a estabelecer como diretriz a criação de colegiado para julgamento em 1.º grau de crimes perpetrados por organizações criminosas, para trazer garantias adicionais aos magistrados, em razão da periculosidade das organizações e de seus membros” (*Inf. 668/STF*).

Como visto, existe expressa possibilidade de lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, criar a **Justiça Militar Estadual** (art. 125, §§ 3.º, 4.º e 5.º), já analisada nos termos da **EC n. 45/2004**.

Por fim, em busca da efetividade do processo e da adequada prestação jurisdicional, a *Reforma do Judiciário* introduziu duas importantes regras (§§ 6.º e 7.º do art. 125):

- a possibilidade de o TJ funcionar **descentralizadamente**, constituindo **Câmaras regionais**, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo;

- o dever de instalar a **Justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

■ 11.8.8. Varas Agrárias e os conflitos fundiários

No tocante à solução de **conflitos fundiários**, o Tribunal de Justiça Estadual proporá a criação de Varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias (art. 126, *caput*, na redação determinada pela EC n. 45/2004), sendo que, sempre que necessário, far-se-ão presentes no local do litígio. No entanto, havendo fatos que atentem contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, a competência será da **Justiça Federal** (art. 109, I, c/c o art. 144, § 1.º, I). [89](#)

Em relação aos conflitos fundiários, cumpre ressaltar a existência de Varas especializadas também em âmbito federal, embora ainda não implementadas na maioria dos Estados da Federação.

Dessa maneira, por exemplo, havendo interesse da União, ou, ainda, do INCRA (autarquia federal), a competência será da Justiça Federal.

Procurando a fixação de limites para a identificação das matérias de competência das Varas Agrárias Estaduais, levando em conta interessante compilação de entendimentos doutrinário e jurisprudencial, *Eneas de Oliveira Matos* fixou como de competência de Vara Especializada Estadual as questões agrárias decorrentes e referentes:

- “do domínio, da posse da terra e de direitos de vizinhança em terras rurais; assim, por exemplo, as ações possessórias, reivindicatórias, usucapião, demarcatórias e divisórias;
- à disputa do solo, seus acessórios naturais e benfeitorias; assim, também, as relativas aos direitos reais sobre propriedades rurais, considerada a especificidade da propriedade imobiliária rural;
- do registro público dos imóveis rurais;
- à prática da atividade agrária, assim consideradas as atividades agrárias de produção, as rurais típicas, como de lavoura, pecuária, hortigranjearia, extrativismo animal e vegetal, exploração florestal, exploração florestal atípica, como a agroindústria, atividade agrária de conservação dos recursos naturais renováveis, atividades agrárias de pesquisa e experimentação, e atividades complementares da atividade agrária; excluindo-se as atividades relacionadas com energia hidráulica, exploração de minérios e recursos marítimos;
- dos negócios com os bens agrários e assim dos contratos agrários, incluindo-se as causas referentes ao crédito e fomento da atividade agrária, e as da produção e comercialização de produtos;
- para ações de reparação de dano com origem na atividade agrária”.

E concluiu: “estão excluídos, como se pode notar, evidentemente, das Varas Agrárias Estaduais os casos em que há competência em razão da pessoa e em

razão da matéria para a Justiça Federal, e também as causas trabalhistas (de competência da Justiça do Trabalho), previdenciárias e tributárias (da Justiça Federal), causas referentes a crimes e contravenções penais (às varas criminais e juizados especiais criminais, destinando-se as Varas Agrárias Estaduais mais para o problema fundiário e de desenvolvimento da atividade agrária) ou, ainda, nas comarcas que, tendo em vista o volume de demandas agrárias, não se justifique a criação de Vara Agrária Estadual, pelo que, nesse caso, deverão ser julgadas perante Vara Cível”. [90](#)

Cabe lembrar que a *Portaria n. 491*, de 11.03.2009 (CNJ), após a Recomendação n. 22/2009, instituiu, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o **Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos**, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos judiciais e a prevenção de novos conflitos.

Em 11.05.2009, ocorreu o *Seminário de Instalação do Fórum Nacional Fundiário*, tendo sido elaboradas propostas de aprimoramento da gestão fundiária no Brasil, destacando-se:

- criação de Varas Agrárias;
- mediação e conciliação dos conflitos agrários;
- combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo;
- capacitação de magistrados.

Sem dúvida, a especialização na matéria caracterizará importante ferramenta para a efetividade e, por conseguinte, para o cumprimento de objetivos da *Reforma do Judiciário*.

Segundo Gilmar Mendes, na cerimônia de instalação do *Fórum*: “uma judicialização efetiva, uma resposta no tempo socialmente certo e politicamente adequado ‘minimiza, reduz e previne outros conflitos’” (*Notícias STF*, 11.05.2009).

■ 11.8.9. Justiça Estadual é competente para julgar crimes comuns entre silvícolas

Por 6 x 3, o STF entendeu, no julgamento do [RE 419.528](#), que “crimes comuns cometidos entre índios serão julgados pela Justiça comum”.

Buscava-se apurar a prática dos crimes de ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal e/ou tentativa de homicídio, atribuídos a 3 índios contra uma menina de 15 anos, também de origem indígena.

Conforme o voto do Ministro Cezar Peluso, acompanhando os fundamentos do voto do Ministro Maurício Corrêa, no tocante ao alcance do art. 109, XI, da CF, no julgamento do HC 81.827/MT (*DJU* de 23.08.2002), a competência será da Justiça Federal quando forem veiculadas “... questões ligadas aos **elementos da cultura indígena** e aos **direitos sobre terras**, não abarcando delitos isolados praticados sem nenhum envolvimento com a comunidade indígena (...). Para o Min. Cezar Peluso, a expressão ‘disputa sobre direitos indígenas’, contida no mencionado inciso XI do art. 109, significa: **a existência de um conflito que, por definição, é intersubjetivo; que o objeto desse conflito sejam direitos indígenas; e que essa disputa envolva a demanda sobre a titularidade desses direitos**. Asseverou, também, estar de acordo com a observação de que o art. 231 da CF se direciona mais para tutela de bens de caráter civil que de bens objeto de valoração estritamente penal”. Assim, “o delito comum cometido por índio contra outro índio ou contra um terceiro que não envolva nada que diga singularmente respeito a sua condição de indígena, não guarda essa especificidade que reclama da Constituição a tutela peculiar prevista no art. 231, nem a competência do art. 109, XI”. Nessas hipóteses, a competência será da Justiça Estadual (RE 419.528/PR, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, 03.08.2006 — *Inf. 434/STF*). [91](#)

■ 11.8.10. Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios

Como vimos, a *Justiça do Distrito Federal e Territórios*, formada pelos Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios, será **organizada** e **mantida**

pela **União** (arts. 21, XIII, 22, XVII; e 33, § 3.º), que também criará os Juizados Especiais e a Justiça de Paz (art. 98, I e II).

Trata-se, portanto, de **leis federais**, alertando-se, contudo, que a **iniciativa** para o encaminhamento dos projetos de lei será **exclusiva** do **TJDFT**, nos termos do **art. 96, II**, da CF/88, destacando-se a **Lei (federal) n. 11.697/2008** (*dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios*) e o *projeto de lei (federal, encaminhado pelo TJDFT)*, dispondo sobre o provimento de mandato eletivo de juiz de paz, já apreciado pelo CNJ no *Parecer de Mérito sobre o Anteprojeto de Lei n. 0005505-50.2011.2.00.0000*.

Ainda, consoante o parágrafo único do art. 110 da CF/88, em relação aos **Territórios**, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais (Justiça Federal comum) caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.

Nesse sentido, em relação ao **Distrito Federal**, *e isso pode ser um detalhe para fazer a diferença nos concursos, cada vez mais exigentes*, como ensina José Afonso da Silva, “... o Poder Judiciário (...), em verdade, não é dele, pois, nos termos do art. 21, XIII, compete à União *organizar e manter* o Poder Judiciário *do* Distrito Federal; ‘do’ no texto constitucional não indica uma relação de pertinência, mas de simples localização, significando aquele que atua no território da unidade federada. Se é à União que cabe organizar e manter, isso significa que o órgão é dela, embora destinado ao Distrito Federal. Nesse particular, a autonomia deste ficou razoavelmente diminuída... uma vez que o Poder Judiciário que nele atua continuará na mesma situação do regime constitucional anterior, tanto que está igualmente previsto que é da competência da União legislar sobre a organização Judiciária do Distrito Federal... (art. 22, XVII)”.⁹²

Para reforçar a regra acima, citamos o art. 53 da Lei Orgânica do DF (Lei n. 11.697/2008), que estabelece serem Poderes do DF, independentes e harmônicos entre si, o **Executivo** e o **Legislativo**, não incluindo o Poder Judiciário, que, como vimos, é organizado e mantido pela **União**.

Nessa linha, destacamos, finalmente, o art. 98, I e II, da CF, que atribuiu à **União** competência para a criação dos *Juizados Especiais* e da *Justiça de Paz*

no Distrito Federal e Territórios.

■ 11.9. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU PARA COMPOR ÓRGÃO JULGADOR DE TRIBUNAL

Com certa frequência, especialmente depois de terem sido fixadas *metas* de julgamento em razão da *Reforma do Judiciário*, tem-se visto a convocação de juízes de primeiro grau para atuar em Tribunal, medida essa veementemente questionada, por suposta afronta ao **princípio do juiz natural**.

Basicamente, alega-se violação à regra contida no art. 5.º, XXXVII e LIII, assim como:

■ **art. 93, III**: “o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância”;

■ **art. 94**: regra do “quinto constitucional”, já estudada e que define a forma de composição dos Tribunais, não havendo previsão de “mera convocação” para atuação em 2.º grau de jurisdição;

■ **art. 98, I**: ao tratar dos juizados especiais, admite a composição das *Turmas Recursais* por juízes de 1.º grau e, portanto, a atuação dos juízes de 1.º grau seria constitucionalmente admitida apenas nos Juizados, não havendo previsão para os Tribunais.

A argumentação parece bastante razoável e consistente, mas o STF, diante da ideia de *efetividade e celeridade processual* (art. 5.º, LXXVIII), nessa ponderação de valores, vem fazendo prestigiar a agilidade, até porque, segundo analisado, as convocações estão sendo feitas com base em lei.

No caso concreto do Estado de São Paulo indicado abaixo, com o objetivo de julgar considerável acervo de processos acumulados, nos termos da lei, foram criadas **câmaras extraordinárias**, integradas por juízes de 1.º grau e presididas por um desembargador.

Conforme apurado, “... o sistema de convocação de magistrados de primeiro grau na Justiça paulista seria uma resposta aos comandos emanados da EC

45/2004, tendo sido implantado nos termos da LC estadual 646/90, dela se distinguindo apenas no aspecto de que a convocação dos magistrados de primeiro grau se daria mediante publicação de edital na imprensa oficial. Acrescentou-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo em nada teria inovado quanto a essa prática, tendo em vista que a Justiça Federal também dela faria uso, com base no art. 4.º da Lei 9.788/99 (...), sem que nenhum de seus julgamentos tivesse sido anulado. Observou-se que a integração dos juízes de primeiro grau nas câmaras extraordinárias paulistas se daria de forma aleatória, sendo os recursos distribuídos livremente entre eles, e que as convocações seriam feitas por ato oficial, prévio e público, não havendo se falar em nomeação *ad hoc*. Assim, tais magistrados não constituiriam juízes de exceção” (*Inf. 581/STF* — [HC 96.821](#), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.04.2010, Plenário, *DJE* de 25.06.2010. Em igual sentido, cf. [RE 597.133/RS](#), j. 17.11.2010, *Inf. 609/STF*).

Destacou-se, ainda, a previsão do art. 96, I, “a”, da CF/88, que permite aos tribunais disporem sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, além da regra, em nosso entender sem o sentido que lhe foi dada, contida no art. 118 da *Lei Orgânica da Magistratura Nacional* — *LOMAN* (LC n. 35/79).

Finalmente, em verdadeiro sopesamento entre, *apenas para argumentar*, afirmou o STF, o *princípio do juiz natural* e o da *segurança jurídica*, uma vez que existem milhares de decisões já proferidas por juízes convocados em 2.º grau, a Suprema Corte fez prevalecer a **segurança jurídica**.

Com o máximo respeito, não concordamos com essa interpretação, parecendo bem coerente o *voto vencido* do Min. Marco Aurélio, que demonstra o sentido totalmente diverso da previsão de substituição contida no art. 118 da *LOMAN*.

■ 11.10. MAGISTRATURA — TETO DE SUBSÍDIO X TETO DE REMUNERAÇÃO — PODER JUDICIÁRIO — CARÁTER NACIONAL E UNITÁRIO

A [Lei n. 13.091, de 12.01.2015](#), fixou o subsídio mensal de Ministro do

Supremo Tribunal Federal, e, portanto, o teto do funcionalismo (cf. *item 9.13.3.6*), no valor de **R\$ 33.763,00**, a contar de 1.º.01.2015.

O Presidente do STF, nos termos da **Res. n. 544, de 13.01.2015**, considerando o escalonamento entre os diversos níveis da **Magistratura da União** previsto no art. 93, V, da CF/88 e no § 2.º do art. 1.º da Lei n. 10.474/2002, tornou público o subsídio mensal dos Magistrados da **União** a partir de 1.º.01.2015, partindo do **teto do funcionalismo** fixado pela referida Lei n. 13.091/2015:

MEMBROS DA MAGISTRATURA	SUBSÍDIO
■ Ministro do STF (teto do funcionalismo)	R\$ 33.763,00
■ Ministro de Tribunal Superior	(-5%) R\$ 32.074,85
■ Juiz de Tribunal Regional e Desembargador do TJDF (lembrando que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário do DF e dos Territórios)	(-5%) R\$ 30.471,11
■ Juiz Federal, Juiz de Vara Trabalhista, Juiz Auditor Militar e Juiz de Direito	(-5%) R\$ 28.947,55
■ Juiz Substituto	(-5%) R\$ 27.500,17

Esse escalonamento também vem sendo estabelecido, por ordem constitucional, em âmbito **estadual**, entre uma **entrância** e outra, de acordo com os níveis locais de organização da magistratura e a partir do teto fixado no art. 37, XI, qual seja, o subsídio dos Desembargadores do TJ, que deve corresponder a, no máximo, 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos

Ministros do STF (no caso, o valor de **R\$ 30.471,11**, ou seja, 90,25% de R\$ 33.763,00).

Estamos diante daquilo que o Ministro Sepúlveda Pertence denominou **escalonamento vertical de subsídios de magistrado** (ADI 2.087-MC), nos termos do art. 93, V, que tem a seguinte redação, de acordo com a EC n. 19/98:

“O subsídio dos **Ministros dos Tribunais Superiores** corresponderá a **95%** do subsídio mensal fixado para os Ministros do **STF** e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a **10%** ou inferior a **5%**, nem exceder a **95%** do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4.º”.

O **CNJ**, ao regulamentar a matéria, nos termos do art. 2.º da **Res. n. 13/2006** (regra mantida pelo CNJ no art. 1.º, parágrafo único, da **Res. n. 14/2006**), estabeleceu que, nos órgãos do Poder Judiciário dos Estados, o **teto remuneratório** constitucional é o valor do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça, que não pode exceder a 90,25% do subsídio mensal de Ministro do STF.

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ajuizou a **ADI 3.854**, discutindo as referidas regras fixadas pelo CNJ em relação à remuneração da magistratura estadual.

Em **28.02.2007**, segundo o *extrato da ata*, o STF, por maioria, concedeu a liminar para, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 37, XI, e § 12, da CF/88, o primeiro dispositivo na redação da EC n. 41/2003, e o segundo introduzido pela EC n. 47/2005, **excluir a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração**, bem como para suspender a eficácia do art. 2.º da Resolução n. 13/2006 e do art. 1.º, parágrafo único, da Resolução n. 14/2006, ambas do CNJ, que fixam, conforme visto, como **limite remuneratório** dos magistrados e servidores dos Tribunais de Justiça, 90,25% do subsídio mensal de Ministro do STF.

De acordo com a decisão do STF, lembrando que foi em sede de liminar,

muito embora tenha sido respeitado o teto de subsídio, este não se confunde com o **teto de remuneração**. Isso porque a Constituição não fixou subteto de subsídio para a magistratura federal, que poderá receber, como remuneração, até o teto do funcionalismo. Conforme vimos, o subteto de 90,25% foi fixado apenas para o âmbito estadual (art. 37, XI).

O art. 93, V, por seu turno, não distinguiu a magistratura em dois âmbitos. De acordo com a Constituição, o **Poder Judiciário** tem caráter **nacional** e **unitário** e por esse motivo é que o art. 93, V, tratou de maneira isonômica a magistratura federal e a estadual, que desempenham funções iguais (jurisdicional) e se submetem a um só estatuto, também de âmbito nacional (art. 93, *caput*, e LC n. 35/79).

Portanto, na medida em que o magistrado federal pode receber até o valor de 100% do subsídio do Ministro do STF (em razão de alguma vantagem funcional e por não haver teto de subsídio previsto no art. 37, XI, que se refere apenas aos magistrados estaduais) e pelo fato de o magistrado estadual não poder ser tratado de modo diferente do federal (**magistratura nacional**), a remuneração do magistrado estadual poderá ser superior ao teto de subsídio (90,25%), mas sempre respeitando o limite do magistrado federal, que é 100% do subsídio do Ministro do STF, qual seja, o teto do funcionalismo. Nesse sentido, destacamos a ementa:

“EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. **Caráter nacional do Poder Judiciário**. Distinção arbitrária. **Ofensa à regra constitucional da igualdade ou isonomia**. Interpretação conforme dada ao art. 37, inc. XI e § 12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2.º da Resolução n. 13/2006 e do art. 1.º, § único, da Resolução n. 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar de ação direta, **aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e os da federal**” (ADI 3.854-MC, Rel. Min. Cezar

Peluso, j. 28.02.2007, Plenário, *DJ* de 29.06.2007) (matéria pendente de julgamento).

■ 11.11. DA JUSTIÇA DE PAZ (ART. 98, II)

■ 11.11.1. Regras gerais

A “Justiça de Paz”, prevista nos arts. 161 [93](#) e 162 [94](#) da Constituição do Império de 1824 (juizado eletivo e de conciliação); art. 104, § 4.º, da Constituição de 1934; [95](#) art. 124, X, da Constituição de 1946; [96](#) art. 136, § 1.º, da Constituição de 1967; [97](#) art. 144, § 1.º, da EC n. 1/69; [98](#) está agora prevista no **art. 98, II, da CF/88**, que determina seja criada, pela União, no DF e Territórios, e pelos Estados, fixando as seguintes características:

■ **remunerada**: segundo decidiu o STF, “a remuneração dos juízes de paz somente pode ser fixada em **lei de iniciativa exclusiva do TJ do Estado**. A regra constitucional insculpida no art. 98 e seu inciso II, segundo a qual a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão a Justiça de Paz, remunerada, não prescinde (*não dispensa*, acrescente-se) do ditame relativo à competência exclusiva enunciada no mencionado art. 96, II, ‘b’. As disposições que atribuem remuneração aos juízes de paz, decorrentes de **emenda parlamentar ao projeto original**, de iniciativa do Tribunal de Justiça estadual, **são incompatíveis com as regras dos arts. 2.º e 96, II, ‘b’, da CF**, eis que eivadas de **vício de inconstitucionalidade formal**, além de violarem, pela imposição de aumento da despesa, o **princípio da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário**” (ADI 1.051, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 02.08.95, Plenário, *DJ* de 13.10.95. *No mesmo sentido*: RE 480.328, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02.06.2009, 1.ª Turma, *DJE* de 28.08.2009 e ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011, Plenário, *DJE* de 26.05.2011);

■ **remuneração: valor fixo e predeterminado**: “os juízes de paz, na qualidade de **agentes públicos**, ocupam **cargo** cuja remuneração deve ocorrer com base em valor fixo e predeterminado, e não por participação no que é recolhido aos cofres públicos. Além disso, os juízes de paz

integram o Poder Judiciário e a eles se impõe a **vedação** prevista no **art. 95, parágrafo único, II**, da Constituição, a qual proíbe a percepção, a qualquer título ou pretexto, de custas ou participação em processo pelos membros do Judiciário” (ADI 954). Entendemos, nesse sentido, nos termos do art. 39, § 4.º, que o juiz de paz deve ser **remunerado exclusivamente** por **subsídio** fixado em **parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI;⁹⁹

- composta de cidadãos **eleitos** pelo voto direto, universal e secreto, sendo que o art. 14, § 3.º, VI, “c”, estabelece, como condição de elegibilidade, a idade mínima de 21 anos;

- juiz de paz exercerá **mandato** de 4 anos;

- terá **competência** para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, **sem caráter jurisdicional**, além de outras previstas na legislação.

O art. 30 do ADCT estabelece que a legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o dia para a eleição prevista no art. 98, II, da Constituição.

Assim, a melhor delimitação do papel da Justiça de Paz deverá vir por meio de lei, seja federal (criada pela União, para o âmbito do DF e Territórios, mediante projeto de lei encaminhado pelo TJDF), seja estadual (disciplinando a Justiça de Paz no respectivo Estado, sendo, também, o projeto de lei encaminhado pelo TJ local), que, como visto, nos termos do art. 98, II, poderá ampliar as atribuições além daquelas fixadas na CF/88.

Poucas são as **leis estaduais** (e no caso no âmbito do **DF** e **Território**, **lei federal**) que dispõem sobre as Justiças de Paz,¹⁰⁰ assim como a jurisprudência do STF sobre a matéria.

Destaca-se, contudo, a **Lei n. 13.454/2000**, do **Estado de Minas Gerais**, que dispôs sobre processo eleitoral, atribuições e competência de juiz de paz.

O Procurador-Geral da República propôs a **ADI 2.938** contra diversos dispositivos da Lei n. 13.454/2000, de Minas Gerais, interpretando o STF, assim, a amplitude deixada à lei estadual, o que, sem dúvida, poderá servir de precedente e parâmetro para as futuras leis estaduais sobre a matéria.

Pedimos vênua para esquematizar as principais conclusões do STF sobre o tema: [101](#)

A) A eleição do juiz de paz foi incluída no “sistema eleitoral global” da CF/88, tendo em vista a regra do art. 14, § 3.º, V e VI

Exceto quanto ao vocábulo “subsidiária”, o STF entendeu constitucionais os arts. 2.º e 3.º da lei estadual, que trazem interessante regulamentação da matéria: “Art. 2.º As eleições para Juiz de Paz serão realizadas simultaneamente com as eleições municipais, na forma estabelecida por esta lei e mediante a aplicação **subsidiária** do Código Eleitoral e da Legislação federal específica. Parágrafo único. O processo eleitoral de que trata este artigo será presidido pelo Juiz Eleitoral competente”. “Art. 3.º O Juiz de Paz é eleito segundo o princípio majoritário, para mandato de quatro anos, pelo voto direto, universal e secreto do eleitorado do distrito ou do subdistrito judiciário respectivo, permitida a reeleição”.

B) A filiação partidária é condição compatível com o exercício da Justiça de Paz

O STF considerou constitucional o art. 4.º da lei estadual: “Art. 4.º Os candidatos a Juiz de Paz e seus suplentes serão escolhidos nas mesmas convenções partidárias que deliberarão sobre as candidaturas às eleições municipais, observadas as normas estabelecidas na legislação eleitoral e no estatuto dos respectivos partidos políticos”.

Deve, assim, ser obedecido o art. 14 da CF. Portanto, o Estado não pode legislar sobre qualquer outra condição de elegibilidade, haja vista tratar-se de matéria eleitoral e, portanto, de competência da União (art. 22, I).

C) As atividades exercidas pelos Juízes de Paz não podem ter nenhum caráter jurisdicional

C.1) Assim, entendeu (interpretando o art. 15 da lei estadual à luz do art. 98, II, da CF/88) como **atribuições do juiz de paz**:

- arrecadar bens de ausentes ou vagos, até que intervenha a autoridade competente;
- zelar pela observância das normas concernentes à defesa do meio ambiente, tomando as providências necessárias ao seu cumprimento, tendo em vista o disposto no inciso VI dos arts. 23 e 24 da CF/88;
- funcionar como perito em processos, diante da previsão do art. 98, II, que fixa a possibilidade de outorga de outras atribuições;
- nomear escrivão *ad hoc* em caso de arrecadação provisória de bens de ausentes ou vagos.

C.2) Em sentido contrário, entendeu **não serem atribuições** do juiz de paz:

- processar auto de corpo de delito e lavrar auto de prisão, por se tratar de matéria processual penal (art. 22, I);
- prestar assistência ao empregado nas rescisões de contrato de trabalho, por se tratar de matéria trabalhista (art. 22, I).

É de observar, finalmente, que o STF concluiu ser **inconstitucional** a previsão do art. 22 da lei mineira que garante ao juiz de paz o direito a prisão especial, em caso de crime comum, até definitivo julgamento, por ser matéria processual penal de competência da União (art. 22, I).

■ 11.11.2. Os juízes de paz integram o Poder Judiciário?

Essa questão foi amplamente discutida no julgamento da **ADI 954**. [102](#)

Segundo decidiu a Corte, sem o comprometimento, nesse ponto, do Min. Ayres Britto, na linha do voto do Min. Celso de Mello, a **Justiça de Paz** se qualifica como verdadeira **magistratura eletiva**, com competência de **caráter judiciário** (como as atividades conciliatórias), sem, contudo, poder exercer atividades jurisdicionais (a vedação é explícita no art. 98, II).

Assim, a Justiça de Paz não é apenas **órgão do Poder Judiciário**, como também **íntegra a organização judiciária local** (art. 98, II, c/c os arts. 92, VII, e 125, § 1.º, todos da CF/88, e art. 112, c/c o art. 17, § 5.º, da LC n. 35/79 — *LOMAN*).

De acordo com as várias manifestações dos Ministros, invocando, inclusive, argumentos de autoridade como o magistério de Pontes de Miranda, os **juízes de paz**:

- são componentes de uma **magistratura especial, eletiva e temporária**;
- não são vitalícios, já que **eleitos** pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos;
- são **inamovíveis** e gozam da **irredutibilidade** de subsídios;
- estão sujeitos às **vedações** do art. 95, parágrafo único, II, da CF/88, destacando-se, no caso em análise (*Lei estadual mineira n. 10.180/90*), a vedação de receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
- não podem ter mais de 70 anos, salvo nos termos de **lei complementar** a ser editada na forma do art. 40, § 1.º, II (cf. *item 11.4.2* e discussão sobre a **EC n. 88/2015**);
- as **atividades** por eles desenvolvidas qualificam-se como **estatais**;
- ocupam **cargos vinculados ao mandato eletivo** (*a atividade não é de caráter privado*), e, assim, a **remuneração** deve partir dos **cofres públicos**,¹⁰³ não se admitindo participação nas custas devidas pelos usuários do serviço (Min. Marco Aurélio).

■ 11.12. DOS PRECATÓRIOS

■ 11.12.1. Regras gerais

Fazemos breve menção aos precatórios, que serão mais bem estudados em processo civil e em direito administrativo.

Lembramos que a matéria foi inicialmente regulamentada no art. 100 da CF/88, sendo alterada pelas **ECs ns. 20/98** (modificação do art. 100 da CF/88), **30/2000** (modificação do art. 100 da CF/88 e acréscimo do art. 78 ao ADCT), **37/2002** (modificação do art. 100 da CF/88 e acréscimo dos arts. 86 e 87 ao ADCT) e, de maneira bastante **complexa** e **tormentosa**, pela **EC n. 62, de 09.12.2009** (modificação do art. 100 da CF/88 e acréscimo do art. 97 ao ADCT).

De modo sintético, pode-se dizer que o precatório judicial é o instrumento através do qual se cobra um débito do Poder Público (pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais), conforme o art. 100 da CF/88, em virtude de sentença judiciária.

Para Humberto Theodoro Júnior, o CPC prevê “... um procedimento especial para as execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública, o qual não tem a natureza própria de execução forçada, visto que se faz sem penhora e arrematação, vale dizer, sem expropriação ou transferência forçada de bens. Realiza-se por meio de simples requisição de pagamento, feita entre o Poder Judiciário e Poder Executivo, conforme dispõem os arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil/73”. [104](#)

Proposta a ação executiva (“execução imprópria”), fundada em título executivo judicial ou extrajudicial, será a Fazenda Pública citada para, nos termos do art. 730, opor embargos, no prazo de **30 dias** (o prazo foi alterado de 10 para 30 dias de acordo com o art. 1.º-B da Lei n. 9.494/97, acrescentado pela MP n. 2.180-35, de 24.08.2001, e está mantido no art. 910, CPC/2015).

No caso de rejeição definitiva dos embargos (lembrar que a sentença proferida contra a Fazenda Pública, ressalvadas as regras trazidas pela **Lei n. 10.352/2001**, que serão mais bem estudadas em processo civil, está sujeita ao reexame obrigatório — art. 475, II, do CPC/73 — correspondente ao art. 496, II, CPC/2015) ou sua não interposição, o juiz, por solicitação do credor, requisitará o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Superior (o que detém a competência recursal ordinária).

De acordo com o § 5.º do art. 100 da CF/88, antigo § 1.º, renumerado pela

EC n. 62/2009, é **obrigatória** a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais, apresentados até **1.º de julho**, fazendo-se o **pagamento** até o **final do exercício seguinte**, quando terão seus valores **atualizados monetariamente**.

A **Súmula Vinculante 17/2009-STF** pacificou o tema ao estabelecer que, “durante o período previsto no § 1.º do art. 100 da Constituição (atual § 5.º), **não** incidem **juros de mora** sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Nos termos do art. 100, § 6.º, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o **sequestro** da quantia respectiva.

Malgrado o entendimento de os bens públicos serem impenhoráveis, a nosso ver, o referido sequestro pode dar-se tanto sobre a quantia indevidamente recebida pelo credor beneficiado como sobre as rendas da Fazenda Pública infratora, segundo decisão do Pleno do STF no julgamento do RE 82.456-RJ, de 07.06.1979 (*RTJSTF* 96/651).

A EC n. 62/2009 mantém a regra introduzida pela EC n. 30/2000 ao determinar (art. 100, § 7.º) que o Presidente do Tribunal competente incorrerá em **crime de responsabilidade** se, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, **respondendo**, também, perante o **CNJ**.

■ 11.12.2. Espécies de precatórios e exceção no caso das obrigações de pequeno valor

Existem duas espécies de precatórios, os de **natureza alimentícia** e os de **natureza não alimentícia**. Aqueles serão pagos preferencialmente (com a exceção do art. 100, § 2.º, introduzido pela EC n. 62/2009), também mediante

precatórios, mas obedecendo a uma ordem própria, conforme, inclusive, reforçam a [S. 655/STF105](#) e o art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 9.469/97. [106](#)

A EC n. 30, de 13.09.2000, ao acrescentar o § 1.º-A ao art. 100 da CF/88, definiu os débitos de natureza alimentícia, **conceito** mantido pela EC n. 62/2009, agora no art. 100, § 1.º, como sendo “... aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.

Interpretou o STF que “a definição contida no § 1.º-A do art. 100 da Constituição Federal (agora § 1.º), de crédito de natureza alimentícia, **não é exaustiva**. (...). Conforme o disposto nos arts. 22 e 23 da Lei n. 8.906/94, os **honorários advocatícios** incluídos na condenação pertencem ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia (...)” (RE 470.407, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006, 1.ª Turma). No mesmo sentido: AI 732.358-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.06.2009, 1.ª Turma, *DJE* de 21.08.2009.

Assim, em momento seguinte, a Corte deixou claro que os honorários advocatícios, por serem de titularidade do advogado, são executados **autonomamente**, independentemente do valor principal a ser recebido pelo cliente, não estando a ele vinculados. Reconhecido o caráter autônomo e também alimentar, a sua execução, quando for o caso de obrigação definida em lei como de pequeno valor, não afronta a regra contida no art. 100, § 8.º, que proíbe o fracionamento dos precatórios ([RE 564.132](#), j. 30.10.2014).

Nessa linha das decisões da Corte, destacamos o art. 85, § 14, do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015), que deixa claro: “os honorários constituem **direito do advogado** e têm **natureza alimentar**, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Todo esse entendimento está consagrado na [SV 47](#) (*DJE* de 02.06.2015), ao estabelecer que “os **honorários advocatícios** incluídos na condenação ou

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de **natureza alimentar** cuja satisfação ocorrerá com a **expedição de precatório** ou **requisição de pequeno valor; observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza**”.

Avançando o tema, destacamos que exceção à regra geral da expedição de precatórios constante do art. 100, *caput*, e § 1.º, foi prevista, inicialmente, pela EC n. 20/98 e, depois, pela EC n. 30/2000, tendo sido mantida na EC n. 62/2009.

Assim, nos termos do art. 100, § 3.º, da CF/88, a obrigatoriedade da expedição de precatório para o pagamento das dívidas públicas **não se aplica** aos pagamentos de obrigações definidas em **leis** como de **pequeno valor** que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, sendo, contudo, **vedada** a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total a montante que seria considerado como de “pequeno valor”. [107](#)

Entendeu, também, o STF que “... é possível o fracionamento de execução de sentença para expedição de requisição de pequeno valor, quando tratar-se de **litisconsórcio facultativo ativo** e não de ação coletiva intentada por legitimado extraordinário ou substituto processual. Precedentes” (RE 459.506-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 12.06.2007, 2.ª Turma, *DJ* de 17.08.2007. No mesmo sentido: RE 501.840-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.09.2009, 2.ª Turma, *DJE* de 09.10.2009, bem como o posicionamento firmado pelo Pleno do STF no julgamento do **RE 568.645**, j. 24.09.2014, *DJE* de 13.11.2014. Como a matéria teve repercussão geral reconhecida, a decisão proferida pela Corte produziu reflexos em relação a pelo menos 1.085 processos que estavam sobrestados — cf. *notícias STF de 24.09.2014*).

Para os fins do disposto no § 3.º do art. 100 e, assim, a conceituação de “**pequeno valor**”, por leis próprias poderão ser fixados **valores distintos** às entidades de direito público, segundo as diferentes **capacidades econômicas**, sendo o **mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de**

previdência social (art. 100, § 4.º). [108](#)

De acordo com o art. 87 do ADCT (**EC n. 37/2002**), para efeito do que dispõem o § 3.º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 do ADCT, **serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação**, observado o disposto no § 4.º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

■ **40 salários mínimos** para Estados e para o Distrito Federal;

■ **30 salários mínimos** para Municípios.

Nesse sentido, o STF entendeu que essa definição de “pequeno valor” “... tem caráter **transitório** e abre margem para que as entidades de direito público (...) disponham livremente sobre a matéria, de acordo com sua capacidade orçamentária” (*Inf. 350/STF*, ADI 2.868/PI).

Conforme já apontamos, o art. 100, § 4.º, dispõe que as entidades de direito público definirão, por leis próprias, o conceito de “pequeno valor” segundo as suas **capacidades econômicas**. Contudo, deverão, nos termos dessa novidade introduzida pela EC n. 62/2009, obedecer a um **valor mínimo**, qual seja, o **valor do maior benefício do regime geral da previdência social**.

A título de curiosidade, a partir de **1.º.01.2015**, o salário de benefício foi fixado no valor máximo de **R\$ 4.663,75** (cf. *Portaria Interministerial MPS/MF n. 13, de 09.01.2015, DOU 12.01.2015*).

■ **11.12.3. Sistemática da “superpreferência” — art. 100, § 2.º (EC n. 62/2009)**

Conforme se apontou, os precatórios de **natureza alimentícia** terão **preferência** sobre todos os demais débitos, **exceto** sobre aqueles mencionados no art. 100, § 2.º.

Esse dispositivo, *novidade introduzida pela EC n. 62/2009*, ao prever o regime da **“superpreferência”**, estabeleceu que os **débitos de natureza**

alimentícia cujos titulares tenham **60 anos de idade ou mais** (*na data de expedição do precatório — expressão declarada inconstitucional pelo STF — veja a seguir!*) ou sejam **portadores de doença grave**, definidos na forma da lei, serão pagos com **preferência** sobre **todos** os demais débitos, até o valor equivalente ao **triplo** do fixado em lei para os fins do disposto no § 3.º (débitos de pequeno valor) do art. 100, admitido o **fracionamento** para essa finalidade, sendo que **o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório**.

O STF, no julgamento das **ADIs 4.357 e 4.425**, na linha da crítica que já fazíamos em edições anteriores, declarou inconstitucional referida expressão “*na data de expedição do precatório*”, pois, “enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, **ultraja a isonomia** (CF, art. 5.º, *caput*) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento”. [109](#)

Determinou-se, portanto, uma preferência sobre aquela que já existia, ou seja, dentre os créditos de natureza alimentícia, aqueles que foram expedidos nas duas situações indicadas terão preferência sobre os demais, também de natureza alimentícia. [110](#)

■ 11.12.4. Compensação de precatório com débitos tributários — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF

Nos termos do art. 100, § 9.º, *introduzido pela EC n. 62/2009*, no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles **deverá** ser abatido, a título de **compensação**, valor correspondente aos **débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos**, *ressalvados* aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.

Conforme afirmamos em edições anteriores, estávamos diante do instituto da **compensação forçada**, o que desnatura a sua essência, além da problemática de haver contestação do valor a ser supostamente compensado, por exemplo, em razão de eventual prescrição.

O STF, de maneira acertada, declarou **inconstitucional** essa sistemática, especialmente por haver exclusivo proveito da Fazenda Pública. Conforme ficou estabelecido na ementa do acórdão, o regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC n. 62/2009, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5.º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5.º, XXXVI), vulnera a separação dos poderes (CF, art. 2.º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5.º, *caput*), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1.º, *caput*) (ADIs 4.357 e 4.425). Esse entendimento pela inconstitucionalidade também se aplica aos valores envolvidos que estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (**RPV**) (**RE 657.686**, j. 23.10.2014, *DJE* de 05.12.2014).

Cabe observar que o STF, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Min. Luiz Fux, **modulou os efeitos da decisão** proferida nas referidas ADIs e, sobre o tema da **compensação** enquanto forma alternativa de pagamento, considerou-a válida somente até a referida data, qual seja, **25.03.2015**, a partir da qual **não será mais possível a quitação de precatórios por tal modalidade**.

■ 11.12.5. Utilização de precatórios para compra de imóveis públicos

De acordo com o art. 100, § 11, é facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado.

■ 11.12.6. Atualização de valores de requisitórios de acordo com os índices da caderneta de poupança — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF

A EC n. 62/2009 introduziu regra bastante complicada em relação à atualização de valores de requisitos.

A partir da promulgação da referida EC, a **atualização** de valores de requisitos, após sua expedição, até o efetivo pagamento, **independentemente de sua natureza**, será feita pelo **índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança**, e, para fins de **compensação da mora**, incidirão **juros simples** no mesmo percentual de juros incidentes sobre a **caderneta de poupança**, ficando **excluída a incidência de juros compensatórios** (art. 100, § 12).

Conforme chegamos a afirmar, essa nova regra **retira** do Poder Judiciário a possibilidade de proceder a efetiva recomposição do valor da moeda com o escopo de preservar o seu poder aquisitivo original. Isso porque atrela, independentemente do valor da inflação, o pagamento à correção da caderneta de poupança.

Ainda, viola o **princípio da isonomia**, pois, se por um lado os **débitos** do poder público são corrigidos pela **poupança**, os seus **créditos**, pela regra atual, são atualizados pela taxa **SELIC**, com correções muito superiores aos índices da poupança.

E, ainda, vislumbramos violação ao **princípio da segurança jurídica** decorrente da **proibição de ofensa à coisa julgada**, pois a nova emenda, delimitando a forma de correção, certamente viola outros critérios de atualização porventura já fixados em sentenças transitadas em julgado.

Toda essa argumentação veio a ser reconhecida pelo STF no julgamento das **ADIs 4.357 e 4.425**, declarando a **inconstitucionalidade** das expressões “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e “independentemente de sua natureza”, constantes do § 12, do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC n. 62/2009. [111](#)

Devemos alertar, contudo, que, no julgamento de questão de ordem suscitada pelo Min. Luiz Fux, o STF, **modulando os efeitos da decisão**, conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da referida

questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até essa data, a saber:

■ “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;” e

■ “ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.

■ 11.12.7. Cessão dos créditos em precatórios a terceiros e a possibilidade de assunção de débitos diretamente pela União

O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, **independentemente da concordância do devedor**, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2.º e 3.º do art. 100, qual seja, a sistemática do privilégio dos créditos de natureza alimentícia para maiores de 60 anos de idade ou nas hipóteses de doença grave, definidas em lei, ou a desnecessidade do precatório para as obrigações definidas em lei como de pequeno valor.

A cessão de precatórios somente produzirá **efeitos** após **comunicação**, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.

Apesar da nova regra, nos termos do art. 5.º, da *EC n. 62/2009*, ficam **convalidadas** todas as **cessões** de precatórios **efetuadas antes de sua promulgação**, independentemente da concordância da entidade devedora.

De acordo com o art. 100, § 16, a seu critério exclusivo e na forma de lei, a **União** poderá **assumir débitos**, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente.

■ **11.12.8. Regime especial para pagamento de crédito de precatórios — art. 100, § 15, da CF/88 e art. 97 do ADCT — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Modulação dos efeitos da decisão — sobrevida ao regime especial por 5 exercícios financeiros a contar de 1.º.01.2016 (ADIs 4.357 e 4.425-QO, j. 25.03.2015)**

Outra novidade (extremamente criticada) introduzida pela *EC n. 62/2009* foi a possibilidade de **lei complementar** estabelecer **regime especial** para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre **vinculações** à **receita corrente líquida** e **forma** e **prazo** de **liquidação**.

Estatui o art. 97, *caput*, do ADCT que até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação da *EC n. 62/2009*, estejam em **mora** na quitação de **precatórios vencidos**, relativos às suas **administrações direta** e **indireta**, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 da Constituição Federal, exceto em seus §§ 2.º, 3.º, 9.º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação da referida Emenda Constitucional.

Por sua vez, o art. 97, § 1.º, I e II, do ADCT faculta ao Chefe do Poder Executivo da entidade federativa devedora optar por duas **formas de pagamento**:

- depósito em **conta especial** do valor referido pelo § 2.º deste artigo; ou
- adoção do **regime especial** pelo prazo de **até 15 anos**, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2.º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da **caderneta de poupança** e de **juros simples** no mesmo percentual de juros incidentes sobre a **caderneta de poupança** para fins de compensação da mora, **excluída a incidência de juros compensatórios**, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. [112](#)

Como se vê, além do parcelamento em até 8 anos que já havia sido instituído pelo art. 33 do ADCT e da moratória fixada pela EC n. 30/2000 em até 10 anos (art. 78 do ADCT), a *EC n. 62/2009* estabeleceu **novo e desarrazoado parcelamento** de até 15 anos, o que poderia ser caracterizado como o maior e mais desastroso “**calote oficial**” e, ainda, **atrelado a percentuais sobre as receitas correntes líquidas das entidades federativas**, fixados em valores nada razoáveis.

O conceito de **receita corrente líquida** está no art. 97, § 3.º, [113](#) do ADCT, e, assim, observa-se que quanto mais incompetente for o governante, menor será o volume financeiro para o pagamento dos precatórios.

Para piorar, a esperada observância de pagamento segundo a **ordem cronológica de apresentação dos precatórios** ficou garantida pela *EC n. 62/2009* em apenas **50%** dos valores destinados para o já combatido método de pagamento dos precatórios, o que viola, sem dúvida, o princípio da isonomia.

Segundo o Min. Celso de Mello, “a norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política (qual seja, acrescente-se, pagamento segundo a *ordem cronológica de apresentação dos precatórios*) traduz um dos mais expressivos postulados realizadores do **princípio da igualdade**, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade à exigência constitucional de tratamento **isonômico** dos credores do Estado...” (ADI 584-MC, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 22.05.92).

Os **outros 50%** do dinheiro destinado para o pagamento das dívidas das Fazendas Públicas seriam utilizados, nos termos do art. 97, § 8.º, do ADCT, segundo **opção** a ser exercida pelos Estados, DF ou Municípios devedores, por ato de seu Chefe do Executivo, uma vez que poderão, isolada ou simultaneamente, utilizar os recursos para:

- pagamento dos precatórios por meio do **leilão**;
- pagamento **à vista** de precatórios não quitados na forma do § 6.º e do inciso I do art. 97 do ADCT, em ordem única e crescente de valor por precatório;

■ pagamento por **acordo direto com os credores**, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação.

Analisando questão de ordem suscitada pelo Min. Luiz Fux no julgamento das **ADIs 4.357 e 4.425**, em 25.03.2015, o STF deliberou sobre referidas formas alternativas de pagamento previstas no regime especial:

■ consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na EC n. 62/2009, desde que realizados **até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades**;

■ decidiram ficar mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.

A garantia para o Poder Público está no art. 97, § 13, do ADCT, já que, enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial, **não poderão sofrer sequestro de valores**, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1.º e o § 2.º do referido artigo.

O **regime especial de pagamento de precatório** previsto no inciso I do § 1.º do art. 97 vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for **superior** ao valor dos recursos vinculados, nos termos do § 2.º, ou pelo prazo fixo de até 15 anos, no caso da opção prevista no inciso II do § 1.º.

Em edições anteriores, fizemos duras críticas a esse regime “especial” introduzido no art. 97 do ADCT.

Apesar de, em certa medida, a nova emenda ter avançado no sentido de fazer com que muitos governantes comecem a pagar precatórios, saindo de criticada inércia, a reforma, contudo, violou diversos preceitos constitucionais, como a **separação de poderes**, cláusula pétrea, pois, pela nova regra, haverá total desprestígio a decisões judiciais já implementadas, criando **insegurança jurídica** e afronta à **coisa julgada** e ao **direito de propriedade**.

Ainda, a *EC n. 62/2009* afrontou o princípio da **razoável duração do processo** (art. 5.º, LXXVIII), pois estabeleceu uma nova e imoral moratória de famigerados 15 anos.

Por sua vez, a flexibilidade da garantia do pagamento segundo a **ordem cronológica dos precatórios** mostra-se inadequada e temerária, violando direitos e garantias individuais, também cláusulas pétreas.

De modo imoral e irresponsável, a nova emenda **flexibilizou a responsabilidade dos governantes** (e, assim, afrontou um dos princípios sensíveis da Constituição, previsto no art. 34, VII, “a”, qual seja, a **República**), desestimulando o pagamento das dívidas das administrações diretas e indiretas e, em afronta à isonomia, criando um mecanismo de tratamento totalmente distinto em relação aos créditos fazendários.

Felizmente, o STF, reconhecendo o disfarçado “calote” oficial, declarou a **inconstitucionalidade do art. 100, § 15**, e de **todo o art. 97 do ADCT**, introduzidos pela *EC n. 62/2009* (ADIs 4.357 e 4.425), não mais admitindo referido regime “especial” de pagamento dos precatórios. [114](#)

Com as nossas críticas, contudo, devemos alertar que o STF, concluindo o julgamento, por maioria e nos termos do voto reajustado do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu **questão de ordem** suscitada e determinou a **modulação dos efeitos da decisão** dando **sobrevida** ao **regime especial** de pagamento de precatórios instituído pela *EC n. 62/2009* por **5 exercícios financeiros a contar de 1.º.01.2016**.

Durante esse período, estão mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, ADCT).

Finalmente, ao CNJ, além de ter sido atribuída competência para monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios pelos entes públicos na forma da decisão proferida nas ADIs, foi delegada competência “para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento

de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório”.

■ 11.12.9. Regime especial para pagamento de crédito de precatórios e os parcelamentos anteriores introduzidos pelos arts. 33 e 78 do ADCT

O constituinte originário de 1988, no art. 33 do ADCT, previu que, ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de **8 anos**, a partir de 1.º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo até 180 dias da promulgação da Constituição.

Por sua vez, a EC n. 30/2000, ao acrescentar o art. 78 ao ADCT, estabeleceu mais uma criticada moratória que, inclusive, está sendo discutida no STF (ADIs ns. 2.356 e 2.362), tendo havido deferimento dos pedidos das medidas cautelares, em **25.11.2010**, suspendendo referido dispositivo até o julgamento final das ADIs (cf. *Inf. 610/STF* — **matéria pendente de julgamento pelo STF**).

De acordo com a regra, ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 do ADCT e suas complementações, e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação da EC n. 30/2000 e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de **10 anos**, permitida a cessão dos créditos, bem como a decomposição das parcelas, a critério do credor.

Conforme sustentado pela maioria dos Ministros no julgamento das medidas cautelares, nas ADIs 2.356 e 2.362: “... o Congresso Nacional, ao impor o

parcelamento impugnado aos precatórios pendentes de liquidação na data de publicação da referida emenda, incidira em múltiplas transgressões à Constituição, porquanto teria **desrespeitado a integridade de situações jurídicas definitivamente consolidadas**, prejudicando, assim, o **ato jurídico perfeito**, a **coisa julgada** e o **direito adquirido**, além de haver violado o **princípio da separação de poderes** e o **postulado da segurança jurídica**” (Inf. 610/STF).

Há que se diferenciar, ainda, a moratória introduzida pelo *constituente originário* (art. 33 do ADCT) daquela instituída pelo *constituente reformador*, no caso, pela EC n. 30/2000, sendo, assim, mais um argumento para sustentar a liminar deferida, já que, enquanto o primeiro é incondicionado, o segundo deve observar as cláusulas pétreas.

De qualquer forma, enquanto se aguarda o julgamento do mérito (**matéria pendente**), cabe observar que o prazo máximo de 10 anos citado não se aplica aos precatórios judiciais originários de **desapropriação de imóvel residencial do credor**, desde que comprovadamente **único** à época da imissão na posse, ficando reduzido para **2 anos** (cf. o § 3.º do art. 78 do ADCT).

Essa regra de **parcelamento** pelo prazo de **10 anos** também **não** se aplica, segundo o art. 86 do ADCT, acrescentado pela **EC n. 37/2002**, aos débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, **cumulativamente**, as seguintes condições:

- terem sido objeto de emissão de precatórios judiciais;
- terem sido definidos como de **pequeno valor** pela lei de que trata o § 3.º do art. 100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 do ADCT;
- estarem, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação da **EC n. 37/2002**.

Isso significa que referidos débitos deverão ser pagos de acordo com a regra geral prevista no art. 100 da CF/88, na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor.

Excepcionalmente, de acordo com o art. 86, § 2.º, do ADCT, se os débitos ainda não tiverem sido objeto de pagamento **parcial**, nos termos do art. 78 do ADCT, poderão ser pagos em **duas parcelas anuais**, se assim dispuser a lei.

O art. 86, § 3.º, do ADCT, acrescentado pela **EC n. 37/2002**, por seu turno, disciplinando os débitos oriundos das hipóteses definidas no art. 78 do ADCT, determina, de maneira correta, que, observada a ordem cronológica de sua apresentação, **os débitos de natureza alimentícia terão precedência para pagamento sobre todos os demais**.

■ 11.12.10. Débitos das entidades da administração indireta: precatórios?

A aplicação da regra do precatório para o pagamento de débitos das **entidades da administração indireta** vem gerando muita discussão.

Anotou José dos Santos Carvalho Filho que “o sistema do precatório é aplicável apenas à Fazenda Pública (art. 100, CF), e no sentido desta evidentemente não se incluem pessoas administrativas de direito privado, como as empresas públicas e sociedades de economia mista...”. [115](#)

Dentro da ideia de “Fazenda Pública”, o autor insere, naturalmente, “as demais entidades administrativas com tal qualificação, como é o caso das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica”. [116](#)

Porém, como o próprio autor alerta, esse não era o entendimento do STF, apesar da regra contida no art. 173, § 1.º, II, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, que, nesse primeiro momento, não se fazia nenhuma distinção entre aquelas que exercem atividades sujeitas a monopólio e aquelas que executam atividades em regime de concorrência.

O STF vinha entendendo, como anota Di Pietro, de modo genérico, que “... os bens das empresas estatais de direito privado **prestadoras de serviço público** são impenhoráveis, aplicando-se à entidade o regime dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (...). Portanto, são bens públicos de uso especial não só os bens das autarquias e das fundações públicas, como

também os das entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos, desde que afetados diretamente a essa finalidade...”. [117](#)

Pedimos vênia, dada a complexidade e importância da matéria, para destacar alguns julgados delimitando essa orientação inicial do STF:

“EMENTA: Distinção entre empresas estatais prestadoras de serviço público e empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito. (...). As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1.º do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. (...). O § 1.º do artigo 173 da Constituição do Brasil **não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público**” (ADI 1.642, Rel. Min. Eros Grau, j. 03.04.2008, *DJE* de 19.09.2008).

“EMENTA: À Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto-lei n. 509/69 e não incidência da restrição contida no artigo 173, § 1.º, da Constituição Federal, que submete a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. **Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência da União Federal e por ela mantido**. Execução. **Observância ao regime de precatório**, sob pena de vulneração do disposto no artigo 100 da Constituição Federal” (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 16.11.2000, *DJ* de 14.11.2002. No mesmo sentido: RE 407.099, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22.06.2004, *DJ* de 06.08.2004; RE 230.161-AgR, j. 17.04.2001, *DJ* de 10.08.2001).

CUIDADO: essa questão voltou a ser discutida pelo **STF** no julgamento do **RE 599.628**, no qual, por 7 x 3, definiu-se que a **Elettronorte** (*Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A*), **empresa de economia mista**, por atuar em um **regime de concorrência** e tendo por **objetivo distribuir lucros aos seus acionistas**, não se enquadra no precedente anterior do RE 220.906 (ECT) e,

assim, **não se sujeita ao regime de precatórios.**

Referido caso citado, o da *ECT*, caracterizava-se como hipótese de **monopólio estatal** e de **atuação exclusiva** por parte da *Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*.

No novo precedente, qual seja, no da *Eletronorte*, por sua vez, o modelo de geração e fornecimento de energia admite a livre-iniciativa e a concorrência e, por isso, deve ser tratado de maneira diversa.

Explicamos: quando o Estado busca o lucro como objetivo principal, no modelo concorrencial, e não se tratando de atividade sujeita a monopólio, dentro da ideia de isonomia com a iniciativa privada (modelo concorrencial), deve despir-se das garantias do pagamento por meio de precatório, que, nos termos do art. 100, *caput*, da CF/88, restringe-se, nesse sentido, aos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas.

Diante do exposto, pedimos vênia para transcrever a ementa do julgamento, alertando os leitores para essa importante distinção feita pelo STF entre modelo concorrencial e atividade sujeita a monopólio (com o destaque para o voto do Min. Marco Aurélio que declarou não aceitar o pagamento por precatório em nenhuma hipótese):

“EMENTA: Os **privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas**. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE) não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição)” (**RE 599.628**, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, j. 25.05.2011, Plenário, *DJE* de 17.10.2011, com repercussão geral).

■ 11.12.11. Intervenção federal ou estadual e não pagamento de precatórios

O desatendimento de um precatório (ordem judicial) por parte do Poder

Público devedor poderá ensejar a intervenção **federal** nos Estados e DF, ou Municípios localizados em TF, ou **estadual** em seus Municípios, por preencher os requisitos dos arts. 34, VI, e 35, IV, respectivamente, da Constituição Federal. Mas, observe-se, a nosso ver essa situação só se configurará quando não houver inclusão no orçamento da verba específica, já que, sendo esta inclusa, caberá o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito e não, desde logo, a intervenção executiva.

No entanto, malgrado nosso entendimento, o STF, indeferindo pedido de intervenção, decidiu “... não configurado o descumprimento voluntário ou injustificado da decisão judicial por parte do Estado de São Paulo, haja vista a inexistência de recursos financeiros para tanto” (cf. *Inf. 296/STF*, fev./2003). Nesse sentido, caminha a jurisprudência do STF que deveria, agora, com o mínimo exigido pela *EC n. 62/2009*, ser modificada:

“EMENTA: O descumprimento **voluntário** e **intencional** de decisão transitada em julgado configura **pressuposto indispensável** ao acolhimento do pedido de intervenção federal. A ausência de voluntariedade em não pagar precatórios, consubstanciada na insuficiência de recursos para satisfazer os créditos contra a Fazenda Estadual no prazo previsto no § 1.º (atual § 5.º, acrescente-se) do artigo 100 da Constituição da República, não legitima a subtração temporária da autonomia estatal, mormente quando o ente público, apesar da exaustão do erário, vem sendo zeloso, na medida do possível, com suas obrigações derivadas de provimentos judiciais. Precedentes” (**IF 1.917-AgR**, Rel. Min. Presidente Maurício Corrêa, j. 17.03.2004, *DJ* de 03.08.2007).

“EMENTA: Precatórios judiciais. Não configuração de atuação **dolosa** e **deliberada** do Estado de São Paulo com finalidade de não pagamento. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. **Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos.** A intervenção, como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. Adoção da chamada relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais concorrentes” (**IF 298**, Rel. p/ o ac. Min.

Gilmar Mendes, j. 03.02.2003, *DJ* de 27.02.2004).

“EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial. Descumprimento voluntário e intencional. **Não ocorrência**. Inadimplemento devido a **insuficiência transitória de recursos financeiros**. Necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas constitucionais. Precedentes. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva a omissão voluntária e intencional do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos financeiros” (**IF 5.101, IF 5.105, IF 5.106, IF 5.114**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.2012, Plenário, *DJE* de 06.09.2012 e *Inf. 660/STF*).

■ 11.13. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

■ 11.13.1. Aspectos gerais e composição do CNJ

Conforme explica Ricardo Chimenti, “a Constituição Federal de 1967, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 07, de 13.04.1977, trazia o **Conselho Nacional da Magistratura** como órgão do Poder Judiciário. O órgão era composto por **sete ministros do C. Supremo Tribunal Federal**, escolhidos pelos próprios ministros, e sua atribuição era nitidamente **correcional** dos atos praticados pelos Magistrados em geral (arts. 112 e 120 da CF/1967, na redação da EC 07/1977). A Constituição Federal de 1988 **aboliu** o Conselho Nacional da Magistratura e garantiu o autogoverno dos tribunais, os quais passaram a ter competência exclusiva para processar e julgar seus Magistrados em casos de infrações disciplinares (ressalvada a possibilidade de o sancionado buscar respaldo nas vias judiciais)”. [118](#)

A **Reforma do Judiciário** (EC n. 45/2004), por sua vez, institui o **Conselho Nacional de Justiça**, composto de **15 membros**, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, tendo sido instalado em **14.06.2005**.

Desses 15 membros, 9 pertencem à Magistratura, sendo, dentre os 6

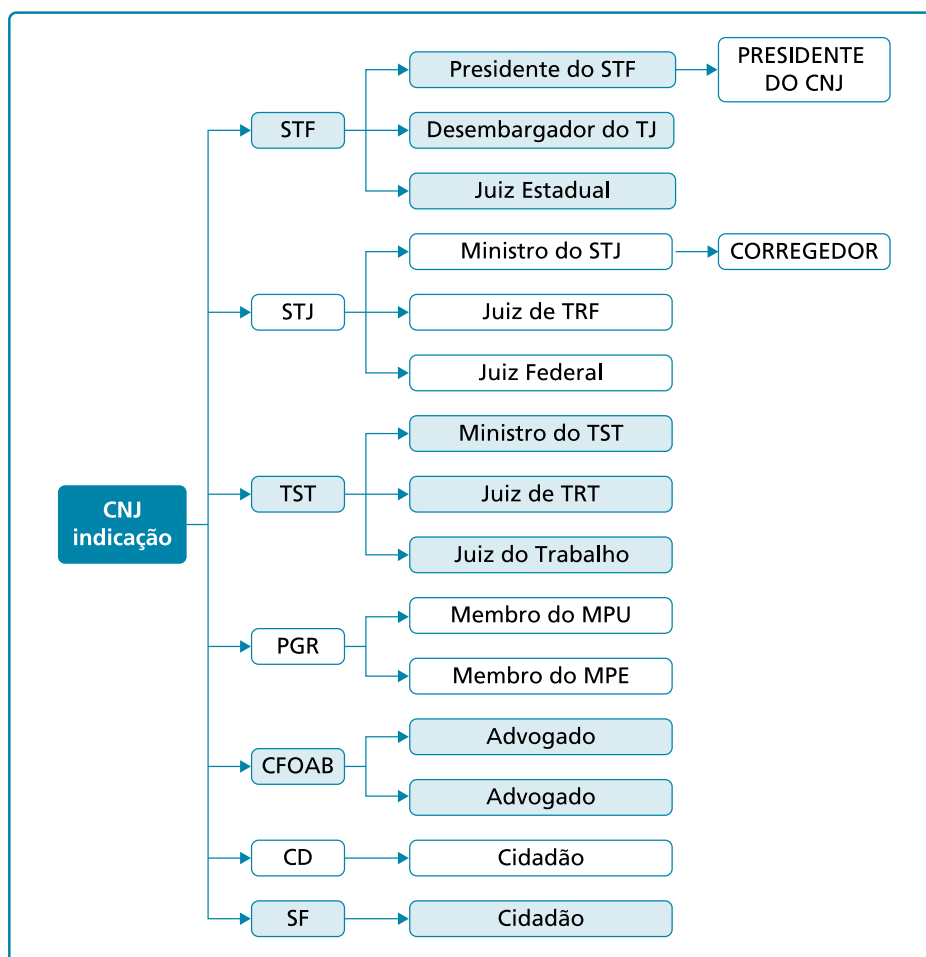
externos, 2 do MP, 2 advogados e 2 cidadãos. Ou, ainda, 9 pertencem ao Judiciário, 4 às funções essenciais (2 membros do MP e 2 da Advocacia) e 2 à sociedade (cidadãos).

Assim, nos termos do art. 103-B, compõem o CNJ:

- o Presidente do Supremo Tribunal Federal ([EC n. 61/2009](#));
- um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
- um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
- um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
- um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
- dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

A seguir, para facilitar a visualização e memorização, apresentamos quadro a demonstrar que dos 15 integrantes:

- **STF** — indica 2, além do Ministro Presidente, membro **nato**, totalizando 3 Conselheiros;
- **STJ** — indica 3;
- **TST** — indica 3;
- **PGR** — indica 2 (sendo que o membro do MPE deverá ser escolhido dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual);
- **CFOAB** — indica 2;
- **CD** — indica 1;
- **SF** — indica 1.



■ 11.13.2. Aperfeiçoamento do CNJ: EC n. 61/2009

A **EC n. 61, de 11.11.2009**, buscou aperfeiçoar o CNJ.

Ao modificar o art. 103-B, I, deixou claro que o CNJ é composto, dentre os seus 15 membros, não por um Ministro do STF (como dizia a redação original da EC n. 45/2004), mas pelo Ministro **Presidente** do STF.

Essa correção, qual seja, o Membro do CNJ não ser qualquer um dos 11 Ministros do STF, mas o seu Presidente, prestigia a agilidade na prestação jurisdicional, pois evita que, supostamente, se o indicado para o CNJ não for o Presidente do STF, fiquem 2 Ministros excluídos da distribuição dos processos (na hipótese, o Presidente do STF pela Suprema Corte e o indicado para o CNJ em relação ao Conselho — art. 103-B, § 1.º — em sua **redação original**), o que redundaria na complicada situação de apenas 9 efetivos julgadores no STF.

Transforma-se o Presidente do STF em um **membro nato** do CNJ, não tendo de ser sabatinado pelo Senado Federal, como se exigia anteriormente.

O art. 103-B, § 2.º, disciplina que apenas os **demais** membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do **Senado Federal** (sabatina). Assim, os Ministros do STJ, TST, enfim, todos os **demais** membros, exceto o Ministro Presidente do STF, enfatize-se, continuam sendo sabatinados pelo SF e nomeados pelo Presidente da República.

Ainda, a EC n. 61/2009 estabeleceu, nos termos do art. 103-B, § 1.º, que o **Conselho** será **presidido** pelo **Presidente do STF** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo **Vice-Presidente do STF**, e não mais por um Conselheiro por ele indicado, conforme constava na redação original do art. 23, I, do *RI/CNJ*. [119](#)

Dessa forma, sendo ocupada a presidência do CNJ por um Ministro do STF, na nova redação, pelo Ministro Presidente do STF, membro natural, a lógica é que a sua substituição (em caso de ausência, impedimento, afastamento, licença etc.) seja pelo Vice-Presidente do STF, e não por outro membro do CNJ, deixando a Presidência sempre atrelada ao órgão de cúpula do Judiciário, qual seja, o STF, e, assim, mantendo o caráter institucional da direção do CNJ. [120](#)

Outro ponto coerente da **EC n. 61/2009** foi a retirada do texto da restrição de

idade para a composição do CNJ que, na redação original, trazida pela EC n. 45/2004, fixava idade mínima de 35 anos e máxima de 66 anos.

Agora, **não há mais nenhuma restrição**, exceto, é claro, aquela estabelecida para a ocupação originária de cada cargo. O objetivo é adequar-se à fixação de ser o Presidente do Conselho o Ministro Presidente do STF, pois é possível que este ocupe a presidência com mais de 66 anos, o que, pela redação original, o impediria de ocupar o CNJ. Ademais, conforme visto, os membros do CNJ exercem funções temporárias (mandato de 2 anos, admitida uma recondução). Nesse sentido, a **Reforma do Judiciário** não fixou limite mínimo ou máximo de idade para os membros do CNMP (art. 130-A).

Por fim, a **EC n. 61/2009** retira a previsão de que o Ministro do STF, que presidiria o Conselho, votaria apenas em caso de empate (*voto de minerva*) — antiga redação do art. 103-B, § 1.º, deixando essa matéria mais bem acomodada no **Regimento Interno do CNJ**, conforme consta em seu art. 5.º (*Res. n. 67, de 03.03.2009*, que aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e dá outras providências).

■ 11.13.3. Inexistência de regulamentação (critérios objetivos) para a indicação dos membros do CNJ

O constituinte reformador não previu um procedimento formal para a escolha dos membros do CNJ, nem mesmo regras específicas dos requisitos dos que serão indicados. A EC n. 45/2004 trouxe regras apenas sobre quem indica, mas não como indica e quais os critérios.

Consoante o que escrevemos em relação ao CNMP, por outro lado, cf. *item 12.2.10.4*, o art. 130-A, § 1.º, determinou que os membros do *Conselho Nacional do Ministério Público* oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, **na forma da lei**, no caso, da **Lei n. 11.372/2006**, existindo, assim, **critérios mais objetivos e predefinidos** (lembrando que essa definição de critérios, contudo, restringiu-se apenas aos membros do CNMP oriundos do Ministério Público).

Referida regulamentação não se direciona ao CNJ. Parece-nos prudente, contudo, que seja adotada também para a escolha dos membros do *Conselho Nacional de Justiça* oriundos do Ministério Público, especialmente em razão de seu caráter democrático, na medida em que se prevê a elaboração de lista tríplice por meio de participação dos membros da carreira em **processo eletivo** (cf. *itens 12.2.10.2 e 12.2.10.3*).

Retomando em relação ao Conselho Nacional de Justiça, o art. 103-B, XI, dispõe que o membro do Ministério Público estadual integrante do CNJ será escolhido pelo Procurador-Geral da República **dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual**. Mas de que forma se dá essa indicação?

Esse procedimento ainda não foi regulamentado por lei. Há, contudo, a edição do **Ofício CNPG-PRES n. 14/2011**, de lavra do senhor Presidente do *Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União*, que adota as regras de formação da lista tríplice por eleição e todo o procedimento previsto para o CNMP nos termos da citada Lei n. 11.372/2006.

Para os demais membros do CNJ, não existem critérios normativos específicos.

Cabe destacar, em relação às vagas ocupadas por **desembargador do TJ** e por **juiz estadual**, sem haver critério objetivo, a edição da **Res. n. 503/2013-STF**, que estabeleceu um denominado “procedimento de escolha e indicação”. Na verdade, e temos que reconhecer a definição de mecanismos de maior transparência, referida resolução prevê a publicação de edital e outras formas de comunicação fazendo **“convite”** para o encaminhamento de **currículos** dos interessados que serão colocados, pela Presidência, à disposição dos Ministros da Corte para a escolha em Sessão Administrativa, devendo a lista estar, também, à disposição do público.

Entendemos extremamente interessante a regulamentação do procedimento de escolha, ao menos com requisitos gerais mínimos, o que poderia ser feito por lei do Congresso Nacional.

Finalmente, na medida em que os membros do CNJ (exceto o Presidente do

STF) serão **sabatinados** pelo Senado Federal, o art. 5.º da **Res. n. 7/SF-2005** estabelece que as indicações de nomes deverão ser acompanhadas de amplos esclarecimentos sobre o candidato e instruídas com os seguintes documentos, o que sinaliza, ao menos, algum parâmetro mínimo para a indicação:

- *curriculum vitae* do indicado no qual conste, detalhadamente, sua qualificação, formação acadêmica e experiência profissional;
- informação do indicado de que não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, de membro ou servidor do Poder ou instituição responsável por sua indicação, salvo, no caso de servidor, se for ocupante de cargo de provimento efetivo e, observada esta condição, não servir junto à autoridade a que esteja vinculado pelo parentesco mencionado;
- declaração sobre eventual cumprimento de sanções criminais ou administrativo-disciplinares, bem como acerca da existência de procedimentos dessa natureza instaurados contra o indicado;
- declaração do indicado de que não é membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de membro desses Poderes.

■ 11.13.4. O CNJ é constitucional?

O STF, em diversos momentos, pronunciou-se pela impossibilidade da instituição do **controle externo da Magistratura** em âmbito estadual, sob pena de se configurar afronta à cláusula pétrea da **separação de Poderes**, de que são corolários o **autogoverno** dos Tribunais e a sua **autonomia administrativa, financeira e orçamentária** (arts. 96, 99 e parágrafos, e 168 da Carta Magna), como se depreende pelo julgamento do Pleno na **ADI 135/PB**, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. em 21.11.1996, que considerou inconstitucional o artigo da Constituição do Estado da Paraíba que previa a criação do **Conselho Estadual de Justiça** como órgão de controle da atividade administrativa e do desempenho

dos deveres funcionais do Poder Judiciário.

Esse *leading case* serviu de paradigma para outros julgamentos no mesmo sentido, todos declarando a inconstitucionalidade das Constituições Estaduais do Pará e do Mato Grosso, as quais instituíam, em âmbito estadual, o **controle externo do Judiciário**, por órgão de composição mista, respectivamente, nas **Adis 137-0/PA e 98-5/MT**.

Em 24.09.2003, o STF consagrou referido entendimento na **S. 649**, que tem o seguinte teor: “é inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades”.

Observa-se, então, que o STF repudia não só a interferência de outros Poderes ou entidades no controle do Judiciário como, também, qualquer atividade externa que atente contra a garantia de **autogoverno** dos Tribunais e a **autonomia administrativa, financeira e orçamentária**, prescritas nos arts. 96, 99 e parágrafos, e 168 da CF, que, segundo fixou a Suprema Corte, **são corolários do princípio da separação de Poderes, erigido, conforme já exposto, à categoria de cláusula pétrea pelo poder constituinte originário no art. 60, § 4.º, III, que nem sequer admite qualquer proposta tendente a aboli-lo**.

Assim, malgrado esses pronunciamentos terem sido enunciados em apreciação do trabalho do **poder constituinte derivado decorrente** (o poder que os Estados-Membros têm de elaborar as suas próprias Constituições — art. 25 da CF c/c o art. 11 do ADCT), pela análise dos referidos votos, parecia que o mesmo entendimento poderia ser proferido em sede da efetiva manifestação do **poder constituinte derivado reformador**.

Embora muitas possam ser as propostas para o necessário **Conselho Nacional da Magistratura** (no caso, a *Reforma do Judiciário* vai preferir a nomenclatura **Conselho Nacional de Justiça — CNJ**), o que deve ser observado é a preservação das garantias de **autogoverno** e **autonomia financeira, administrativa e orçamentária** do Poder Judiciário, sob pena de se configurar emenda **tendente a abolir a separação de Poderes**, vedando-se,

desta feita, a participação dos membros dos outros Poderes no controle da Magistratura. [121](#)

Ives Gandra da Silva Martins anotou que, “... mais do que uma questão de inconstitucionalidade — a meu ver, fere o § 4.º, inciso III, do artigo 60, todo o artigo 103-B da EC n. 45 no que concerne à participação de outros polos — trata-se de questão de incompatibilidade, esta transposição de um modelo de controle parlamentar para um país de perfil presidencial. É tornar um Poder Técnico, como é o Judiciário, em poder controlado politicamente, ou seja, sujeito a interpretações próprias de opções e oportunidades políticas, mais do que de soluções exclusivamente técnicas”. [122](#)

Em **09.12.2004** foi ajuizada a **ADI 3.367** pela AMB — Associação dos Magistrados Brasileiros, questionando a constitucionalidade do CNJ por afronta aos arts. 2.º e 18 da CF/88, além de vício formal. Em **13.04.2005**, o STF, por unanimidade, afastou o vício formal de inconstitucionalidade, como também não conheceu da ação quanto ao § 8.º do art. 125. No mérito, o Tribunal, por maioria (7 x 4), julgou totalmente improcedente a ação, **considerando constitucional o Conselho Nacional de Justiça** (*vide Inf. 383/STF*). O Conselho foi instalado no dia **14.06.2005**, com a solenidade de posse de seus 15 integrantes.

A presença de não magistrados, segundo o STF, não viola a cláusula pétrea inserta no art. 60, § 4.º, III, e art. 2.º da CF/88 (separação de Poderes): “(...) Subsistência do núcleo político do princípio, mediante **preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente** (...)”. [123](#) Nesse particular, asseverou o Min. Relator: “pode ser que tal presença seja capaz de erradicar um dos mais evidentes males dos velhos organismos de controle, em qualquer país do mundo: o **corporativismo**, essa moléstia institucional que obscurece os procedimentos investigativos, debilita as medidas sancionatórias e desprestigia o Poder” (grifamos — *Notícias STF*, 13.04.2005 — 21h08).

Ainda, na linha da constitucionalidade do CNJ, podemos lembrar: **a)** o CNJ integra o Judiciário (art. 92, I-A) e, com isso, afasta-se a combatida ideia de

controle externo; **b)** em sua composição, os integrantes da Magistratura superam a maioria absoluta (em um total de 9, dentre 15 — art. 103-B, I-XIII); **c)** possibilidade de revisão das decisões do CNJ pelo STF (art. 102, I, “r”).

■ 11.13.5. Atribuições do CNJ e o controle de suas decisões pelo STF (limites?)

■ 11.13.5.1. Regras gerais

Nos termos do art. 103-B, § 4.º, compete ao Conselho o controle da **atuação administrativa** e **financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo **Estatuto da Magistratura**:

- zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

- zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e *determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa*;

- representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a

Administração Pública ou de abuso de autoridade;

- rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

- elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Dentro dessa perspectiva estabelecida na Constituição Federal, o art. 1.069 do **CPC/2015** estabelece que o CNJ promoverá, periodicamente, pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas no novo Código;

- elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

Os **diversos tipos de processos** poderão ser **registrados** observando-se (art. 43 do RICNJ) as seguintes **classes processuais**: Inspeção; Correição; Sindicância; Reclamação Disciplinar; Processo Administrativo Disciplinar; Representação por Excesso de Prazo; Avocação; Revisão Disciplinar; Consulta; Procedimento de Controle Administrativo; Pedido de Providências; Arguição de Suspeição e Impedimento; Acompanhamento de Cumprimento de Decisão; Comissão; Restauração de Autos; Reclamação para Garantia das Decisões; Ato Normativo; Nota Técnica; Termo de Compromisso; Convênios e Contratos; Parecer de Mérito sobre Anteprojeto de Lei.

Assim, pode-se afirmar que o CNJ busca contribuir para que a **prestação jurisdicional seja efetiva**, zelando, nos termos do art. 37, pela observância dos princípios da **legalidade**, **impressoalidade**, **moralidade**, **publicidade** e **eficiência**.

Conforme disponibilizado no site do CNJ, o trabalho compreende:

- “planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias;
- modernização tecnológica do Judiciário;
- ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social;

- garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais”.

As atribuições acima expostas e contidas no art. 103-B, § 4.º, foram bem esquematizadas no site do CNJ. Vejamos:

- **“política judiciária:** zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos e recomendações;
- **gestão:** definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário;
- **prestação de serviços ao cidadão:** receber reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado;
- **moralidade:** julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções administrativas;
- **eficiência dos serviços judiciais:** melhores práticas e celeridade: elaborar e publicar semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País”.

■ 11.13.5.2. O CNJ não exerce função jurisdicional

Observa-se, portanto, que o CNJ **não exerce função jurisdicional** e os seus atos poderão ser revistos pelo STF, orientação essa firmada no julgamento da **ADI 3.367:**

“Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. **Órgão de natureza exclusivamente administrativa.** Atribuições de controle da **atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura.** Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do STF.

Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos arts. 102, *caput*, inc. I, letra r, e 103-B, § 4.º, da CF. **O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o STF e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito**” (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.04.2005, *DJ* de 22.09.2006 — grifamos).

Dessa forma, por estarem as atribuições do CNJ restritas ao controle da atuação administrativa, financeira e disciplinar dos órgãos do Poder Judiciário a ele sujeitos, pode-se afirmar ser o CNJ um **órgão meramente administrativo (do Judiciário)**.

■ 11.13.5.3. O CNJ tem atribuição para exercer o controle de constitucionalidade?

O tema é bastante interessante e ainda precisa de uma definição por parte do STF.

Naturalmente, o CNJ não poderá exercer o controle abstrato de constitucionalidade, declarando, em tese e como questão principal de eventual PCA, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, sob pena de usurpar a competência do STF.

Contudo, parece-nos que, no **caso concreto**, de **modo incidental**, desde que se trate de ato **flagrantemente inconstitucional**, o CNJ poderia declarar a inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo, em verdadeiro controle difuso, e na linha do estabelecido para o TCU nos termos da S. 347/STF.

CUIDADO: devemos alertar que o tema, tanto para o TCU como para o CNJ, está em discussão na Suprema Corte.

Em relação ao **TCU**, conforme anotou o Min. Gilmar Mendes, “a própria **evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil**, verificada desde então, **está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da Súmula 347** em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição

de 1988” (*pendente de análise pelo Pleno*). [124](#)

Por sua vez, no tocante ao **CNJ**, o Min. Celso de Mello, sob a alegação de que o Conselho não tem função jurisdicional, mas **apenas administrativa**, afastou a possibilidade de exercício de controle de constitucionalidade, mesmo que incidental (*pendente de apreciação pelo Plenário*). [125](#)

Essa perspectiva, contra o nosso entendimento, parece a linha a ser seguida pela Corte. Muito embora não tenha sido decisão do Plenário, destacamos o julgamento do **MS 27.744** (1.^a Turma/STF, j. 14.04.2015), pelo qual se declarou não ser possível o controle de constitucionalidade de lei pelo **CNMP** por se tratar de órgão administrativo “cuja atribuição se circunscreveria ao controle da legitimidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público federal e estadual (CF, art. 130-A, § 2.º)” (*Inf. 781/STF* — acórdão ainda não publicado no fechamento desta edição).

■ **11.13.5.4. STF: órgão de cúpula jurisdicional e órgão de cúpula administrativa, financeira e disciplinar (amplitude)**

O **STF**, por sua vez, além de ser **órgão de cúpula jurisdicional e nacional do Judiciário brasileiro**, apresenta-se, a partir da EC n. 45/2004, também, como **órgão de cúpula administrativa, financeira e de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (disciplinar)**, já que, nos termos do art. 102, I, “r”, todas as decisões do CNJ serão passíveis de revisão pelo STF.

Resta saber qual a amplitude de análise pelo STF. Poderá haver revisão do mérito administrativo?

O tema precisa ser mais bem definido. Uma constatação, contudo, já é certa, qual seja, não poder funcionar o STF como mera sede recursal dos atos do CNJ. Segundo o Min. Sepúlveda Pertence, busca-se “**não converter a Corte, por meio do mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho**” (MS 26.710-QO/DF e MS 26.749-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 02.08.2007, *Inf. 474/STF*)

(**matéria pendente de julgamento pelo STF**, apesar de ambos os MSs com pedido de desistência homologado).

Aliás, de acordo com o art. 115, § 6.º, do *RICNJ*, dos atos e decisões do Plenário do Conselho não cabe recurso (**na sede administrativa**), e sim **revisão** pelo STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), conforme visto. Nesse sentido, o art. 106 do *RICNJ*, na redação dada pela *Emenda Regimental n. 1/2010*, estabelece: “o CNJ determinará à autoridade recalcitrante, sob as cominações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo **que não o STF**”; mas, retome-se, qual a amplitude dessas revisões?

Parece ter razão o Min. Gilmar Mendes, em voto monocrático, quando afirma que “a ordem constitucional assegura ao Conselho Nacional de Justiça espectro de poder suficiente para o exercício de suas competências (art. 103-B, CF/88), não podendo esta Corte substituí-lo no exame discricionário dos motivos determinantes de suas decisões, quando estas não ultrapassem os limites da **legalidade** e da **razoabilidade**”. Assim, referidos limites podem, nessa primeira análise, orientar a atuação do STF no cumprimento da competência fixada no art. 102, I, “r” (**MS 26.209/DF**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.10.2006, *DJ* de 27.10.2006, tendo sido negado seguimento ao MS e, em consequência, prejudicado o pedido de medida liminar. Houve interposição de agravo regimental — **matéria pendente de julgamento pelo STF**).

■ 11.13.5.5. O STF não deve ser considerado mera instância ordinária revisora das decisões administrativas do CNJ

A competência originária do STF para analisar atos do CNJ (art. 102, I, “r”, da CF/88) está intimamente relacionada à **qualidade** do referido ato administrativo, devendo haver **inovação** na ordem jurídica.

Isso porque, em nosso entender, se o CNJ não inovar a ordem jurídica, não poderemos considerar o ato do CNJ, que nada decidiu, passível de ataque.

Explicamos: vamos imaginar que o ato contestado no CNJ seja, por exemplo,

emanado de determinado tribunal inferior que não nomeou candidatos aprovados em concurso público e que foram convocados para exames admissionais.

Se o CNJ também entender no sentido da inexistência do direito líquido e certo à nomeação, simplesmente confirmando (mantendo) a decisão do tribunal inferior, não podemos dizer que o ato do CNJ é o ato coator, novo e passível de ataque. Na verdade, no caso citado, o CNJ apenas confirmou decisão de Presidente de Tribunal que não nomeou candidatos aprovados em determinado certame. Trata-se de **deliberação negativa** que não substituiu ou desconstituiu o ato originalmente contestado.

Assim, eventual mandado de segurança, no exemplo, não poderá ser originário no STF, sob pena de se caracterizar **acesso per saltum à Suprema Corte** e combatida **supressão de instância**. Nesse sentido:

“No pedido de revisão administrativa da pontuação de títulos obtida pelo impetrante, o CNJ entendeu que nada havia a decidir, porque a questão fora apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Deliberação negativa do CNJ que não substituiu o ato originalmente questionado. Ausência de abuso ou ilegalidade na decisão do CNJ. Não conhecimento desse pedido por incompetência do STF (...). **Impossibilidade de se transformar o STF em instância revisora das decisões administrativas do CNJ**. Ausência de direito líquido e certo do impetrante para a oferta de serventias vagas, não constantes no edital” (**MS 27.026**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.11.2010, Plenário, *DJE* de 21.02.2011).

“O STF não se reduz à singela instância revisora das decisões proferidas pelo CNJ. Em especial, descabe compelir o CNJ a adotar a providência de fundo entendida pela parte interessada como correta, se **a decisão impugnada não tiver alterado relações jurídicas ou, de modo ativo, agravado a situação de jurisdicionado**. Cabe à parte interessada, que não teve sua pretensão atendida no campo administrativo com uma decisão positiva-ativa, buscar a tutela jurisdicional que, no caso, é **alheia** à competência originária do STF” (**MS 28.133-AgR**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24.03.2011, Plenário, *DJE* de 11.04.2011. No mesmo sentido: **MS 28.549-AgR**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.03.2013, Plenário, *DJE* de 08.04.2013; **MS 27.712-AgR**; **MS 27.148-**

AgR; MS 28.202-AgR; MS 29.118-AgR).

■ 11.13.6. O CNJ tem controle da função jurisdicional do Judiciário?

Ou, em outras palavras, pode o CNJ rever as decisões dos magistrados no âmbito do processo?

Não. Como visto, a competência do CNJ restringe-se ao **âmbito administrativo**, não podendo adentrar na análise dos atos jurisdicionais, nem rever o conteúdo da decisão judicial. Para tanto, a parte deve valer-se dos meios processuais estabelecidos pelo sistema recursal.

Nesse sentido, posiciona-se o STF: “(...) Conselho Nacional de Justiça: competência restrita ao controle de atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário a ele sujeitos” (MS 25.879-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23.08.2003, *DJ* de 08.09.2006).

Ou, ainda: “(...) não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça — embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário — qualifica-se como órgão de caráter administrativo, **não dispondo de atribuições institucionais que lhe permitam exercer fiscalização da atividade jurisdicional dos magistrados e Tribunais** (...)” (CNJ — *Natureza Jurídica — Controle da Função Jurisdicional — Inadmissibilidade* — MS 27.148-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.05.2008, *DJE* de 26.05.2008 — íntegra no *Inf. 507/STF*.) (A liminar foi confirmada na decisão monocrática proferida em 20.05.2010, *DJE* de 26.05.2010 — íntegra no *Inf. 589/STF*.)

■ 11.13.7. Corregedoria Nacional de Justiça e Ministro-Corregedor do CNJ

A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça.

O art. 103-B, § 5.º, dispõe que o **Ministro do STJ** exercerá a função de **Ministro-Corregedor** e ficará excluído da distribuição de processos no âmbito

de seu Tribunal, competindo-lhe, além das **atribuições** que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:

- receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;
- exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correção geral;
- requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

■ 11.13.8. O CNJ, no exercício de suas atribuições correcionais, atua originariamente (primariamente) e concorrentemente com as Corregedorias dos tribunais

Cabe lembrar a edição da **Res. n. 135, de 13.07.2011**, do **CNJ**, que dispõe sobre a *uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar* aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidades, além de dar outras providências.

Em 16.08.2011, foi ajuizada a **ADI 4.638**, pela **Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)**, questionando diversos dispositivos do ato.

Entre tantas discussões, está a suposta colisão entre a **atribuição correcional do CNJ** e a **atuação das corregedorias locais dos Tribunais**.

Em 19.12.2011, o Min. Marco Aurélio deferiu, em parte, o pedido de medida liminar e, dentre vários assuntos, deu interpretação conforme ao art. 12, *caput*, da referida resolução para estabelecer a **competência subsidiária** do CNJ em âmbito disciplinar (*Notícias STF*, da referida data).

O art. 12, *caput*, da Res. n. 135/2011/CNJ prescreve que, para os **processos administrativos disciplinares e para a aplicação de quaisquer penalidades previstas em lei**, é competente o **Tribunal** a que pertença ou esteja subordinado o Magistrado, **sem prejuízo da atuação do Conselho Nacional de Justiça**.

O Plenário do STF, por **6 x 5**, em 02.02.2012, **não referendou** a citada

liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que havia suspenso a vigência do referido dispositivo.

Dessa forma, de acordo com a decisão, a regra do art. 12 da Res. n. 135/2011/CNJ é **autoaplicável** e, portanto, o **CNJ**, no exercício de suas **atribuições correcionais**, atua **originariamente (primariamente)** e **concorrentemente** com as Corregedorias dos tribunais, podendo, assim, instaurar, independentemente da atuação das Corregedorias locais, procedimentos administrativos disciplinares aplicáveis aos magistrados, bem como, após o devido processamento e observado o contraditório e a ampla defesa, aplicar as penalidades previstas na lei. [126](#)

■ 11.13.9. Prerrogativa de foro

Outra regra interessante está prevista no **art. 52, II**, modificado pela EC n. 45/2004, que amplia as hipóteses de julgamento de **crime de responsabilidade** pelo **SF**, fazendo incluir os membros do Conselho Nacional de Justiça.

Então, se perguntarem se um juiz estadual ou um cidadão podem cometer crime de responsabilidade, a resposta será afirmativa desde que seja membro do Conselho Nacional de Justiça.

E as infrações penais comuns?

A EC n. 45/2004 **não** estabeleceu nenhuma regra. Quando aprovada a “**PEC Paralela da Reforma do Judiciário**” (PEC n. 29-A/2000-SF e PEC n. 358/2005-CD), a competência passará a ser do STF (nova redação a ser dada ao art. 102, I, “b”).

Diante do atual silêncio, então, que órgão teria competência para processar e julgar a infração penal comum praticada por membro do CNJ?

A infração penal comum, eventualmente praticada por membro do CNJ, será apurada seguindo a **regra individual**, inclusive de prerrogativa de função se houver, de cada membro. Assim, se, supostamente, o ato for praticado por Ministro do STJ, a competência será do STF (art. 102, I, “c”), se por Juiz de Direito Estadual, do TJ, art. 96, III, com a ressalva do crime eleitoral etc. (cf.

esquematização no *item 10.4.15*).

■ 11.13.10. Outras regras sobre o CNJ

Sem ter a previsão de participação como membros, o art. 103-B, § 6.º, dispõe que junto ao Conselho oficialão o **Procurador-Geral da República** e o **Presidente do Conselho Federal da OAB**.

Nesse particular, consoante decidiu o STF, “... ainda que disponha o art. 103-B, § 6.º, da Constituição Federal que ‘junto ao Conselho oficialão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil’, **a ausência destes às sessões do Conselho não importa em nulidade das mesmas**” (MS 25.879-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23.08.2006, *DJ* de 08.09.2006).

Como maneira de cumprir todas as atribuições previstas, o art. 103-B, § 7.º, estabelece que a União, inclusive no DF e nos Territórios, criará **ouvidorias de justiça**, competentes para receber **reclamações** e **denúncias** de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.

O Conselho, com sede na Capital Federal (Brasília), foi alocado como **órgão do Poder Judiciário** (art. 92, I-A) e tem atuação em todo o território nacional.

Sobre importante desdobramento do princípio do contraditório e da ampla defesa no tocante à intimação pessoal de terceiros em PCAs, cf. *item 14.10.29.4*.

Por fim, no exercício de suas atribuições constitucionais, o CNJ vem editando resoluções, sendo que algumas já foram reconhecidas pelo STF como **atos normativos primários**, procedendo-se à inovação da ordem jurídica a partir de parâmetros constitucionais e, assim, sobre elas, admitindo-se a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade por meio de ADI genérica (cf. *item 6.7.1.2.17*).

■ 11.14. SÚMULA VINCULANTE

■ 11.14.1. Duas realidades: a morosidade da Justiça e as teses jurídicas repetitivas

A **morosidade da Justiça**, amplamente conhecida e criticada, apresenta-se como uma das grandes mazelas do Judiciário deste começo de novo século.

No Tribunal de Justiça de São Paulo, para se ter um exemplo, convivía-se com um inconcebível “tempo morto” de até 5 anos para distribuir um único recurso de apelação, apesar de a tese decidida pelo juízo monocrático (e aguardando distribuição para nova apreciação pelo Tribunal) já estar pacificada no STF.

Sem dúvida, a divergência jurisprudencial, atrelada ao sistema recursal pátrio, bem como as diversas causas repetidas em que a Fazenda Pública figura como parte, vem contribuindo para agravar a chamada **“crise da Justiça”**.

A súmula vinculante, como se verá, em nosso entender, sem dúvida contribui para, ao lado de tantas outras técnicas, buscar realizar o comando fixado no art. 5.º, LXXVIII, também introduzido pela Reforma do Poder Judiciário e, na mesma medida, estabelecer a segurança jurídica, prestigiando o princípio da isonomia, já que a lei deve ter aplicação e interpretação uniformes.

Nesse sentido, o art. 926, CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015), estabeleceu que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la **estável, íntegra e coerente**. Sem dúvida, o legislador conferiu um sentido bastante técnico a esses **vetores principiológicos** a partir de uma concepção de **dignidade da pessoa humana**, considerando os princípios da **segurança jurídica**, da **proteção da confiança** e da **isonomia** (art. 927, § 4.º, CPC/2015) (cf. *item 6.6.5.2*).

■ 11.14.2. As “famílias” do direito

Em importante obra, René David procurou agrupar os direitos em **“famílias”** como técnica “... para facilitar, reduzindo-os a um número restrito de tipos, a

apresentação e a compreensão dos diferentes direitos do mundo contemporâneo”. [127](#)

Assim, é possível identificar: **a)** família romano-germânica; **b)** família da *common law*; **c)** família dos direitos socialistas; **d)** *outras acepções da ordem social e do direito*, sendo, segundo René David, o direito muçulmano, o direito da Índia, os direitos do Extremo Oriente e os direitos da África e de Madagascar.

Essa divisão em *famílias*, muito embora a sua utilidade, vem sendo posta em dúvida, sobretudo pelos processualistas, tendo em vista as diferenças entre os vários sistemas processuais.

Apesar da crítica, podemos valer-nos de dois grandes “modelos” para o estudo da súmula vinculante: **a)** modelo do direito codificado continental (*civil law*); **b)** modelo do precedente judicial anglo-saxão (*common law*).

Como anotou Tavares, “há uma radical oposição e (aparente) incompatibilidade entre os modelos mencionados. Realmente, enquanto o *modelo codificado* (caso brasileiro) atende ao pensamento abstrato e dedutivo, que estabelece premissas (normativas) e obtém conclusões por processos lógicos, tendendo a estabelecer normas gerais organizadoras, o modelo jurisprudencial (caso norte-americano, em parte utilizado como fonte de inspiração para criação de institutos no Direito brasileiro desde a I República) obedece, ao contrário, a um raciocínio mais concreto, preocupado apenas em resolver o caso particular (pragmatismo exacerbado). Este modelo do *common law* está fortemente centrado na primazia da decisão judicial (*judge made law*). É, pois, um sistema nitidamente *judicialista*. Já o direito codificado, como se sabe, está baseado, essencialmente, na lei...”. [128](#)

E continua Tavares: “o chamado *precedente* (*stare decisis*) utilizado no modelo judicialista, é o *caso já decidido*, cuja decisão primeira sobre o tema (*leading case*) atua como fonte para o estabelecimento (indutivo) de diretrizes para os demais casos a serem julgados. Esse precedente, como o princípio jurídico que lhe servia de pano de fundo, haverá de ser seguido nas posteriores decisões como paradigma (ocorrendo, aqui, portanto, uma aproximação com a ideia de súmula vinculante brasileira)”. [129](#)

■ 11.14.3. Influência do *stare decisis* da família da *common law*

Podemos afirmar, então, que, embora com as suas particularidades, o instituto do *stare decisis* influenciou a criação da súmula vinculante do direito brasileiro.

Segundo Agra, “... o sistema do *Common Law*, de tradição anglo-saxônica, onde prepondera o *stare decisis* (*et quia non movere*), o precedente judiciário é fonte de direito, isto é, detém valor normativo”. [130](#)

Fala-se, então, em “*stare decisis et quia non movere*”, ou seja, “mantenha-se a decisão e não se perturbe (se altere) o que foi decidido”, apesar de o precedente não ser de aplicação absoluta. [131](#)

Nesse sentido, para evitar o risco da instabilidade (já que os juízes poderiam decidir de maneira divergente, criando várias leis contraditórias), estabeleceu-se o instituto dos **precedentes**, devendo todos os demais juízes julgar conforme o decidido no caso concreto e pelo órgão hierárquico superior.

Anotam Sormani e Santander ao analisar o caso particular do sistema norte-americano, que “... a descentralização do Judiciário, própria do federalismo, e a importância atribuída às decisões judiciais por força do *judicial review* exigiram para a funcionalidade do sistema a adoção do efeito vinculante aos precedentes judiciais”. [132](#)

■ 11.14.4. Influência da Alemanha e da Áustria

Podemos asseverar, ainda, que a súmula vinculante também encontra antecedentes na Alemanha, cujo sistema concentrado de controle de constitucionalidade já havia influenciado o estabelecimento da ação declaratória de constitucionalidade introduzida pela EC n. 3/93.

Na lição de Gilmar Mendes, o § 31, ns. 1 e 2, da Lei do *Bundesverfassungsgericht* confere **força de lei e efeito vinculante** às decisões do Tribunal. A vinculação também decorre da Lei Fundamental. [133](#)

Em igual medida, destacamos o art. 140, n. 7, da Constituição da Áustria, que fixa o efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e

administrativos.

■ 11.14.5. A influência do direito português

Usando a expressão “força obrigatória geral”, o art. 282, n. 1, da Constituição portuguesa de 1976 consagra a ideia de **vinculação geral** e de **força de lei** (semelhante à lei) decorrente das decisões do Tribunal Constitucional no controle abstrato, o que, sem dúvida, também influenciou o direito brasileiro. [134](#)

■ 11.14.6. A evolução do “direito sumular” no Brasil (fase colonial — influência do direito português)

Pode-se afirmar que, na fase colonial, as Ordenações Afonsinas não conheceram nenhum instituto de vinculação, que somente apareceu, em 1521, com as Ordenações Manuelinas (Liv. V, Tít., 58, § 1.º) por meio da instituição dos **“assentos”**.

As Ordenações Filipinas, aperfeiçoando, criaram o instituto dos **“Assentos da Casa de Suplicação”**, com força vinculativa (Liv. I, Tít. 5, § 5.º).

Como sustenta Cármen Lúcia, “os antecedentes portugueses do Direito brasileiro é que por primeiro dão notícia dos *assentos*, que eram firmados pela Casa da Suplicação, nos termos das Ordenações Manuelinas, com a finalidade precípua de extinguir dúvidas jurídicas suscitadas em causas submetidas a julgamento. As soluções dadas aos casos que se constituíssem objeto de dúvida por aquela Casa e definidas nos *assentos* convertiam-se em normas, tendo sido adotada essa figura pelas Ordenações Filipinas. Se entre os juízes da Casa de Suplicação não se chegasse a uma deliberação quanto à dúvida, em razão de sua extensão a todos eles, a matéria seria encaminhada para a solução do Rei, que a sanaria mediante lei, alvará ou decreto”. [135](#)

Em seguida, a denominada **“Lei da Boa Razão”**, de **18.08.1769**, excluiu a possibilidade de *assentos* pelos Tribunais do Rio de Janeiro e da Bahia.

O Príncipe Regente D. João, mediante **Alvará Régio de 10.05.1808**, por seu

turno, instituiu a “Casa da Suplicação do Brasil”, restabelecendo a prática dos assentos.

■ 11.14.7. A evolução do “direito sumular” no Brasil (após a independência)

A **Lei n. 5, de 20.10.1823**, manteve em vigor as Ordenações Filipinas.

Posteriormente, a **Lei n. 18, de 18.09.1828**, criou o **Supremo Tribunal de Justiça** (09.01.1829 — 27.02.1891) e, em seu art. 19, estabeleceu interessante procedimento para a uniformização da legislação. [136](#)

O **Decreto Legislativo n. 2.684, de 23.10.1875**, regulamentado pelo **Decreto n. 6.142, de 10.03.1876**, deu **força de lei**, no Império, aos **assentos** da *Casa da Suplicação* de Lisboa, bem como competência para o *Supremo Tribunal de Justiça* tomar outros, também **com força de lei**, até que fossem derogados pelo Poder Legislativo.

A **Constituição da República** (1891) extinguiu, definitivamente, a prática dos assentos, apesar da posterior previsão dos **prejulgados** no CPC/39 (art. 861) e no art. 902 da CLT/43 (cujo § 4.º determinava que, uma vez estabelecido o prejudgado pela *Câmara de Justiça do Trabalho*, os Conselhos Regionais do Trabalho, as Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízes de Direito investidos da jurisdição da Justiça do Trabalho ficavam obrigados a respeitá-lo).

Por influência do então Ministro do STF **Victor Nunes Leal**, instituiu-se a **Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal**, por intermédio de Emenda Regimental de 28.03.1963, aprovando-se, em 13.12.1963, os primeiros 370 enunciados.

Segundo relatou em palestra proferida em Belo Horizonte em 12.08.1964, a súmula atende a vários objetivos: “é um sistema oficial de referência dos precedentes judiciais, mediante a simples citação de um número convencional; distingue a jurisprudência firme da que se acha em vias de fixação; atribui à jurisprudência firme consequências processuais específicas para abreviar o julgamento dos casos que se repetem e exterminar as protelações

deliberadas”.[137](#)

Ainda, como bem anota, “... razões pragmáticas, inspiradas no princípio da igualdade, aconselham que a jurisprudência tenha relativa estabilidade. Os pleitos iguais, dentro de um contexto social e histórico, não devem ter soluções diferentes. A opinião leiga não compreende a contrariedade dos julgados, nem o comércio jurídico a tolera, pelo natural anseio de segurança”.[138](#)

Cabe alertar, no entanto, que referidas súmulas não têm caráter vinculante, mas, simplesmente, persuasivo.

Posteriormente, nessa escalada evolutiva, destaca-se a instituição do **Superior Tribunal de Justiça** (STJ) pela CF/88, instalado em 07.04.1989 (Lei n. 7.746/89) e, nos mesmos termos do STF, com a possibilidade de editar súmulas orientando o posicionamento do Tribunal em relação a determinados assuntos, sem, contudo, caráter vinculante.

Finalmente, a **EC n. 45/2004** introduziu no direito brasileiro a **súmula vinculante**, que foi regulamentada pela **Lei n. 11.417, de 19.12.2006**.

■ 11.14.8. Prenúncios da súmula vinculante em âmbito constitucional

A valorização substancial dos precedentes, em âmbito constitucional, decorre do **efeito vinculante** em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública tendo em vista a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade (em razão do caráter dúplice ou ambivalente das ações constitucionais) proferida no controle concentrado (art. 102, § 2.º, da CF/88 e art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99 — Rcl — Agr-QO 1.880-SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 06.11.2002, e *Inf. 289/STF*, 2002).

Essa tendência é resgatada pelo legislador da **Reforma do Judiciário** ao ampliar o efeito vinculante que já era previsto na ADC para a ADI, modificando a redação do art. 102, § 2.º, nos seguintes termos:

“as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

■ 11.14.9. Prenúncios da súmula vinculante no âmbito do direito processual civil

Alfredo Buzaid apresentou, seguindo o exemplo do art. 861 do Código de 1939, a figura dos **assentos vinculantes** no Projeto de Código de Processo Civil, na década de 1970.

Como se sabe, no CPC/73 (“Código Buzaidiano”), a ideia não foi aceita, limitando-se o Código, em seu art. 476, a tratar “da uniformização da jurisprudência”.

Entretanto, especialmente por meio das últimas minirreformas do Código Buzaidiano de 1973, o legislador vem **aumentando o poder decisório dos relatores** e a “vinculação” sugestiva decorrente de posicionamentos já sumulados e pacificados nos tribunais superiores, o que se observa, dentre outros, pelos seguintes artigos do CPC/73: 120, parágrafo único; 285-A, *caput*; [139](#) 475, § 3.º; 475-L, § 1.º; 741, parágrafo único; [140](#) 479; 481, parágrafo único; 518, § 1.º; 544, §§ 3.º e 4.º; 555, § 1.º; 557, *caput*; e 557, § 1.º-A.

Essa perspectiva está mantida no CPC/2015, cujo art. 926 estabeleceu ser dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la **estável, íntegra e coerente** (para uma análise dessa inegável valorização dos precedentes e sua correspondência com o CPC/73, cf. *item 6.6.5.2*).

■ 11.14.10. Os contornos da súmula vinculante na EC n. 45/2004

O art. 103-A traz as seguintes regras quanto à **súmula vinculante**:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de **dois terços** dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na

imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1.º A súmula terá por objetivo a **validade**, a **interpretação** e a **eficácia** de normas determinadas, acerca das quais haja *controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica*.

§ 2.º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a **aprovação**, **revisão** ou **cancelamento** de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a **ação direta de inconstitucionalidade**.

§ 3.º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá **reclamação** ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

O instituto da **súmula vinculante**, inicialmente estendido para os Tribunais Superiores (arts. 105-A e 112-A), foi retirado pela CCJ do Senado, permanecendo a regra exclusivamente para o **STF**. A matéria que voltou para a CD (“PEC Paralela do Judiciário”) fixa a possibilidade de edição de **súmula impeditiva de recurso**, mas este é outro tema que ainda depende de aprovação em 2 turnos pela Câmara dos Deputados.

Podemos, então, esquematizar, em ordem crescente de “vinculação”, as modalidades de súmulas que o direito brasileiro atualmente consagra:

■ **súmula persuasiva**: súmula sem vinculação, indicando simplesmente o entendimento pacificado do tribunal sobre a matéria. Atualmente, todos os tribunais a estabelecem. O impacto, no entanto, é meramente processual e indicativo, por exemplo, o julgamento monocrático pelo relator nos tribunais (art. 557, § 1.º-A, do CPC/73, com correspondência no art. 932, IV e V, CPC/2015);

■ **súmula impeditiva de recursos**: introduzida pela **Lei n. 11.276, de**

07.02.2006, nos termos do art. 518, § 1.º, do CPC/73, determina mais um *requisito de admissibilidade* do recurso de **apelação**, qual seja, a sentença de primeira instância não estar em conformidade com súmula do STJ ou do STF. Se a decisão estiver nos termos de seu sentido exato, todo e qualquer recurso ficará “barrado”. Como visto, a “PEC Paralela de Reforma do Poder Judiciário”, que ainda precisa ser aprovada, prevê a súmula impeditiva de recursos para o STJ e o TST, o que ampliará a regra que hoje se limita ao recurso de apelação. Ainda, devemos observar que, no CPC/2015 (art. 1.011, I, c/c o art. 932, IV), a admissibilidade negativa é transferida para o Relator no Tribunal, e não mais para o juízo *a quo* que proferiu a sentença, podendo decidir monocraticamente (no Novo Código, não há mais juízo de admissibilidade pelo juiz que proferiu a sentença — art. 1.010, § 3.º). Nesse sentido, o Relator poderá negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do STF ou do STJ; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetidos; incidente firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência);

■ **súmula de repercussão geral (também impeditiva de recurso)**: como vimos, o art. 102, § 3.º, da CF/88 foi regulamentado pela Lei n. 11.418/2006, que, acrescentando o art. 543-A do CPC/73, estabeleceu (§ 7.º) a **súmula de repercussão geral**, que também será **impeditiva de recurso** (mas restrita ao recurso extraordinário), já que, uma vez firmada a tese de que o fundamento jurídico não apresenta repercussão geral, nenhum recurso extraordinário será conhecido, devendo ser considerado automaticamente não admitido. Essa perspectiva foi mantida no CPC/2015 (arts. 1.035 e 1.036);

■ **súmula vinculante**: introduzida pela EC n. 45/2004 — instrumento exclusivo do STF, o enunciado de súmula vinculante, uma vez editado, produz efeitos de vinculação para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública. A medida foi regulamentada pela Lei n. 11.417/2006.

■ **11.14.11. As regras trazidas pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006 — súmula vinculante**

■ 11.14.11.1. *Competência*

O **STF**, de ofício ou mediante provocação, é o **exclusivo** tribunal competente para a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante.

■ 11.14.11.2. *Objeto*

O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas.

■ 11.14.11.3. *Requisitos para a edição*

Devem existir reiteradas decisões sobre **matéria constitucional** em relação a normas acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre estes e a Administração Pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.

■ 11.14.11.4. *Legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante*

Como vimos, além de o STF poder, **de ofício**, editar, rever ou cancelar súmula vinculante, o processo poderá ser, também, iniciado mediante **provocação**.

O art. 103-A, § 2.º, da CF/88 dispõe que, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade (que são os mesmos que também podem propor a ação declaratória de constitucionalidade, conforme a redação conferida ao art. 103, *caput*, da CF/88 pela EC n. 45/2004).

Nesse sentido, a Lei n. 11.417/2006 previu tanto os **legitimados autônomos** como os **incidentais**.

De forma **autônoma**, sem a necessidade de se ter um processo em andamento, são legitimados (cf. o art. 3.º da Lei n. 11.417/2006) os mesmos da **ADI** e da **ADC**, previstos no art. 103 da CF/88 (CF, art. 103-A, § 2.º), bem como, e acrescentando, o **Defensor Público-Geral Federal** e os **Tribunais Superiores**, os **TJs dos Estados** ou do **DF e Territórios**, os **TRFs**, os **TRTs**, os **TREs** e os **Tribunais Militares**.

Os **Municípios** também passaram a ter legitimação ativa, porém como **legitimados incidentais**. Isso porque, conforme o art. 3.º, § 1.º, da lei, os Municípios só poderão propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante **incidentalmente** ao curso de processo em que sejam parte, o que, contudo, **não autoriza a suspensão dos referidos processos**.¹⁴¹

■ 11.14.11.5. Procedimento

O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, além das regras contidas na CF/88 e na **Lei n. 11.417/2006**, ao disposto no **Regimento Interno do STF**.

Para tanto, a **Emenda Regimental n. 46/2011** acresceu os arts. 354-A a 354-G ao *RISTF*, regulamentando o procedimento, que passamos a reproduzir.

Observamos que a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante seguem um **rito próprio** e **específico**, não se admitindo a interposição de recurso extraordinário para esse fim, nem mesmo a utilização da ADI ou da ADPF.

Isso não impede que a Suprema Corte, a partir de certo julgamento, proponha, **preenchidos os requisitos constitucionais**, a edição, a revisão ou o cancelamento de determinado enunciado.

O art. 354-E do *RISTF* permite que a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante **verse** sobre **questão com repercussão geral reconhecida**, caso em que poderá ser apresentada por qualquer Ministro logo após o julgamento de mérito do processo, para deliberação imediata do

Tribunal Pleno na mesma sessão.

Pois bem, avançando o regramento regimental, recebendo a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, a Secretaria Judiciária a autuará e registrará ao **Presidente**, para apreciação, no prazo de 5 dias, quanto à **adequação formal da proposta**.

Dispõe o art. 3.º, § 2.º, da Lei n. 11.417/2006, que, no procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por **decisão irrecurável**, a **manifestação de terceiros** (*amicus curiae*) na questão, nos termos do *Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal*.

De acordo com o art. 354-B do *RISTF*, verificado o atendimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publicará **edital** no sítio do Tribunal e no *Diário da Justiça Eletrônico*, para **ciência** e **manifestação** de **interessados** no prazo de 5 dias, encaminhando a seguir os autos ao **Procurador-Geral da República** para manifestação, salvo, conforme estabelece o art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 11.417/2006, nas propostas que houver formulado.

Devolvidos os autos com a manifestação do Procurador-Geral da República, o Presidente submeterá as manifestações e a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula aos Ministros da *Comissão de Jurisprudência*, em meio eletrônico, para que se manifestem no prazo comum de 15 dias; decorrido o prazo, a proposta, com ou sem manifestação, será submetida, também por meio eletrônico, aos demais Ministros, pelo mesmo prazo comum, sendo que, ao final, o Presidente submeterá a proposta à deliberação do Tribunal Pleno, mediante inclusão em pauta.

A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula, com efeito vinculante, dependerão de decisão tomada por pelo menos **2/3** dos membros do STF, em sessão plenária, manifestando-se no mesmo sentido pelo menos 8 dos 11 Ministros.

No prazo de 10 dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o STF fará publicar, em seção especial do *Diário da Justiça Eletrônico* e do *Diário Oficial da União*, o enunciado

respectivo.

O teor da proposta de súmula aprovada, que deve constar do acórdão, conterá cópia dos debates que lhe deram origem, integrando-o, e constarão das publicações dos julgamentos no *Diário da Justiça Eletrônico*.

Nos termos do art. 6.º da Lei n. 11.417/2006, a **proposta** de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão.

Por derradeiro, a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula tramitará sob a forma eletrônica, e as informações correspondentes ficarão disponíveis aos interessados no sítio do STF.

■ 11.14.11.6. Efeitos da súmula

A partir da **publicação** do enunciado da súmula na Imprensa Oficial, ela terá **efeito vinculante** em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

Assim, a vinculação repercute somente em relação ao **Poder Executivo** e aos **demais órgãos do Poder Judiciário**, não atingindo o Legislativo no exercício de sua função típica de legislar (nem o Executivo ao exercer a função atípica normativa, quando, por exemplo, edita medida provisória), sob pena de se configurar o **“inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição”**, conforme anotado pelo Ministro Peluso na análise dos efeitos da ADI (**Rcl 2.617 e item 6.7.1.8**), nem mesmo em relação ao próprio STF, sob pena de se inviabilizar, como visto, a possibilidade de revisão e cancelamento de ofício e, portanto, a adequação da súmula à evolução social.

Esclarecemos que, no tocante ao **Legislativo**, parece razoável imaginar a vinculação no concernente ao exercício de sua função atípica jurisdicional e, claro, se houve alguma interpretação pela Suprema Corte em termos de procedimento.

A ideia central é permitir que o Legislativo possa ter liberdade para o exercício

de sua função típica normativa.

Por sua vez, no que respeita ao **STF**, quando dizemos que não haverá vinculação, estamos querendo explicitar a possibilidade de a Corte poder rever o enunciado. Mas, claro, até que isso aconteça, o entendimento materializado na súmula continuará sendo aplicado. Não parece razoável que um Ministro, monocraticamente, deixe de aplicar a súmula até que ela venha a ser modificada ou cancelada.

Finalmente, um tema bastante interessante foi decidido pelo STF no que se refere a súmula vinculante que contenha **matéria penal**.

Na opinião de alguns Ministros, se o tema fixado na súmula vinculante tratar de matéria penal e for estabelecida interpretação menos benéfica, deveria ser aplicado o princípio da irretroatividade. Assim, por exemplo, o Min. Celso de Mello entendeu que determinado Tribunal estadual, que apreciava **fato** ocorrido antes da edição de certa súmula vinculante, não estava vinculado ao seu conteúdo, já que fora estabelecida interpretação mais gravosa (cf. voto **vencido** proferido na Rcl 7.358/STF).

Em certo sentido, chegou a sustentar que a súmula vinculante seria como um “ato normativo”, e, nesse sentido, deveria ser aplicado o art. 5.º, XL, que assegura que a “lei” penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

CUIDADO: esse **entendimento**, contudo, **não vingou no STF**.

De acordo com a Corte, a regra a ser aplicada é a do art. 103-A, *caput*, que diz que a súmula vinculante aprovada, ou a que venha a ser modificada ou cancelada, terá efeito vinculante a partir de sua **publicação na Imprensa Oficial**.

Isso significa que, se um Tribunal de segundo grau estiver analisando um recurso, ou o juízo monocrático decidindo determinada questão em relação a **fato** praticado em momento **anterior à edição da súmula vinculante**, deverá, **necessariamente, aplicar o entendimento firmado na referida súmula**, mesmo que se trate de **matéria penal** e de **interpretação menos benéfica**. Nesse sentido, confira:

“EMENTA: (...). Com efeito, a tese de que o julgamento dos recursos

interpostos contra decisões proferidas antes da edição da súmula não deve obrigatoriamente observar o enunciado sumular (após sua publicação na Imprensa Oficial), *data venia*, não se mostra em consonância com o disposto no art. 103-A, *caput*, da Constituição Federal, que impõe o **efeito vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, a partir da publicação da súmula na Imprensa Oficial**. Desse modo, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em 10 de setembro de 2008, ao não considerar recepcionada a regra do art. 127 da LEP, afrontou a *Súmula Vinculante 09*” [142](#) (**Rcl 7.358**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24.02.2011, Plenário, *DJE* de 03.06.2011). [143](#)

Deixamos claro que a vinculação se dá a partir da **publicação** da súmula vinculante na Imprensa Oficial, conforme visto. Assim, todas as decisões judiciais **que vierem a ser proferidas** a partir de sua publicação, ou os atos administrativos, também após a edição e publicação da súmula vinculante, deverão respeitar o entendimento firmado, sob pena do cabimento de **reclamação**.

Nesse ponto, naturalmente, **não caberá reclamação** (apesar de outros instrumentos serem adequados, como o recurso extraordinário, o mandado de segurança etc.) se a **decisão judicial** ou o **ato administrativo** que se pretende atacar for **anterior** à edição da **súmula vinculante**.

E cuidado, não basta, para vincular, que exista súmula que, por ser persuasiva, tem natureza meramente processual e não constitucional. A súmula, a propósito, para vincular e permitir o ajuizamento de reclamação no caso de sua contrariedade, negativa de vigência ou aplicação indevida, terá de ser **vinculante**, observando-se todo o procedimento e as formalidades estudados.

■ 11.14.11.7. Modulação dos efeitos

Na mesma linha da regra da modulação dos efeitos da decisão prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/99 (ADI), o art. 4.º da Lei n. 11.417/2006 estabelece que a súmula com efeito vinculante tem **eficácia imediata**, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 dos seus membros, poderá restringir os efeitos

vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse público**.

■ **11.14.11.8. Revogação ou modificação da lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante**

Vimos que, revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou por provocação, procederá à sua **revisão** ou **cancelamento**, conforme o caso.

Para se ter um exemplo, entendemos que a **SV 9/STF**, tendo em vista a modificação do art. 127 da LEP (Lei n. 7.210/84) pela Lei n. 12.433/2011, precisa passar, necessariamente, por um processo de revisão ou cancelamento, já que não mais se conforma ao conteúdo da nova regra (cf. discussão no *item 11.14.12*) (**matéria pendente**).

■ **11.14.11.9. Da reclamação**

Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá **reclamação 144** ao STF, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.

Como já referimos, **não caberá reclamação** (apesar de, repetimos, haver outros instrumentos adequados, como o recurso extraordinário, o mandado de segurança etc.) se a **decisão judicial** ou o **ato administrativo** que se pretende atacar for **anterior** à edição da **súmula vinculante**. Isso porque a **vinculação** se dará a partir da **publicação** da súmula vinculante na Imprensa Oficial.

Em se tratando de **omissão** ou ato da **Administração Pública**, o uso da reclamação só será admitido **após o esgotamento das vias administrativas**. Trata-se de instituição, por parte da lei, de *contencioso administrativo atenuado* ou de *curso forçado* e *sem violar o princípio do livre acesso ao Judiciário* (art. 5.º, XXXV), na medida em que o que se veda é somente o ajuizamento da

reclamação e não de qualquer outra medida cabível, como a ação ordinária, o mandado de segurança etc.

Julgando procedente a reclamação, o STF anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, dependendo do caso.

■ 11.14.11.10. *Responsabilidade do administrador público*

Nos termos do *art. 64-B da Lei n. 9.784/99*, introduzido pela Lei n. 11.417/2006, acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas **cível, administrativa e penal**.

O objetivo é muito claro, qual seja, como diagnosticado, diminuir a presença da Fazenda Pública como parte em processos jurisdicionais idênticos cuja tese jurídica já tenha sido decidida pelo STF, com efeito vinculante.

■ 11.14.11.11. *Responsabilidade dos magistrados?*

A lei não fixou, ao menos explicitamente, nenhuma sanção aplicável aos juízes em caso de descumprimento de súmula vinculante, garantindo-se, como anotou o Ministro Marco Aurélio, “a liberdade do magistrado de apreciar os elementos para definir se a conclusão do processo deve ser harmônica ou não com o verbete”. [145](#)

Tal liberdade não significa, contudo, que o magistrado jamais poderá ser responsabilizado em caso do seu descumprimento.

Isso porque, se o desrespeito ao efeito vinculante da súmula for **infundado e reiterado, doloso e desproporcional**, entendemos que poderá caracterizar-se violação aos **deveres funcionais**, viabilizando-se, assim, a abertura do competente **procedimento administrativo disciplinar** com possíveis

aplicações das penalidades legais.

De acordo com o art. 2.º do *Código de Ética da Magistratura*, [146](#) impõe-se ao magistrado a primazia pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos.

Como se sabe, tanto a Constituição como a Lei n. 11.417/2006 estabelecem que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, a **súmula vinculará os órgãos do Poder Judiciário**.

Em igual medida, o art. 35, I, da *LC n. 35/79* (LOMAN) estabelece serem deveres do magistrado **cumprir** e fazer cumprir, com independência, serenidade e **exatidão**, as **disposições legais** e os atos de ofício.

Essa questão chegou a ser “ventilada” no STF após analisar diversos *habeas corpus* contra decisões do **STM** que, contrariando entendimento da Corte, ou seja, de que a competência é da Justiça Federal, continuava a aceitar a competência da Justiça Castrense (Militar) para processar e julgar civis denunciados pelo crime de falsificação da Carteira de Habilitação Naval (CIR) ou habilitação de arrais-amador.

Conforme noticiado, os Ministros que compõem a 2.^a Turma do STF sugeriram que o Min. Celso de Mello elaborasse *Proposta de Súmula Vinculante* (PSV) refletindo o entendimento pacificado, embora não sumulado, de **incompetência da Justiça Militar**. [147](#)

O Min. Gilmar Mendes, não obstante tenha expressado a sua resistência para a edição de súmulas vinculantes em matéria penal (**apesar de possíveis**), sustentou, para o referido caso, a sua adoção, especialmente diante do risco de **prescrição** em razão da **demora** no julgamento (em função do indevido encaminhamento dos autos para julgamento perante o STM e, posteriormente, a remessa para a Justiça Federal) e, assim, a consequente **impunidade**.

Em 16.10.2014, o STF aprovou a **SV n. 36**, com a seguinte redação: “compete à **Justiça Federal comum** processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de

Habilitação de Amador (CHA), **ainda que expedidas pela Marinha do Brasil**” (DJE de 24.10.2014).

Com a edição da referida súmula vinculante, esperamos que cesse esse comportamento reiterado do STM. Isso porque, conforme assinalou o Min. Lewandowski, “... o **descumprimento** de uma **súmula vinculante** de forma **infundada** e **sem justificação** pode ensejar a **responsabilização do magistrado**, porque é um **ato de insubordinação**” (*Notícias STF*, 13.09.2011).

■ 11.14.12. As 53 súmulas vinculantes (a de número 30 com a publicação suspensa)

Apresentamos, abaixo, as 53 súmulas vinculantes editadas pelo STF, as quais, em razão de sua importância, devem ser bem consideradas para as provas de concursos:

■ **Súmula Vinculante n. 1:** “ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar n. 110/2001”;

■ **Súmula Vinculante n. 2:** “é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”;

■ **Súmula Vinculante n. 3:** “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”;

■ **Súmula Vinculante n. 4:** “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”;

■ **Súmula Vinculante n. 5:** “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Dessa maneira, fica **superada** a S. 343/STJ que dizia exatamente o contrário; [148](#)

■ **Súmula Vinculante n. 6:** “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”;

■ **Súmula Vinculante n. 7:** “a norma do § 3.º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”;

■ **Súmula Vinculante n. 8:** “são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5.º do Decreto-lei n. 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”;

■ **Súmula Vinculante n. 9:** “o disposto no artigo 127 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no *caput* do artigo 58”. **CUIDADO:** referida súmula vinculante foi aprovada em **12.06.2008** (*DJE* de 20.06.2008) e, assim, antes do advento da **Lei n. 12.433, de 29.06.2011**, que, em nosso entender, acarreta a indiscutível necessidade de sua **revisão** ou **cancelamento**, já que, modificando a regra anterior, inova o ordenamento de maneira **mais benéfica**. Isso porque, se na redação original do art. 127 da LEP, na interpretação dada pelo STF, a prática de **falta grave** ocasionava a perda de **todos** os dias remidos, na redação atual (do art. 127 da LEP), estabelecida pela Lei n. 12.433/2011, o juiz poderá revogar até o **limite máximo** de **1/3 do tempo remido**, observado o art. 57 da LEP; [149](#)

■ **Súmula Vinculante n. 10:** “viola a cláusula de reserva de plenário (cf. artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”;

■ **Súmula Vinculante n. 11:** “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”;

■ **Súmula Vinculante n. 12:** “a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”;

■ **Súmula Vinculante n. 13:** “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.

■ **Súmula Vinculante n. 14:** “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”;

■ **Súmula Vinculante n. 15:** “o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”;

■ **Súmula Vinculante n. 16:** “os artigos 7.º, IV, e 39, § 3.º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”;

■ **Súmula Vinculante n. 17:** “durante o período previsto no § 1.º do artigo 100 da Constituição (atual § 5.º, acrescente-se), não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”;

■ **Súmula Vinculante n. 18:** “a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7.º do artigo 14 da Constituição Federal”;

■ **Súmula Vinculante n. 19:** “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”;

■ **Súmula Vinculante n. 20:** “a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa — GDATA, instituída pela Lei n. 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n. 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1.º da Medida Provisória n. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos”;

■ **Súmula Vinculante n. 21:** “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”;

■ **Súmula Vinculante n. 22:** “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n. 45/04”;

■ **Súmula Vinculante n. 23:** “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”;

■ **Súmula Vinculante n. 24:** “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”;

■ **Súmula Vinculante n. 25:** “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”;

■ **Súmula Vinculante n. 26:** “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 8.072/90,

sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”;

■ **Súmula Vinculante n. 27:** “compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”.

■ **Súmula Vinculante n. 28:** “é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”;

■ **Súmula Vinculante n. 29:** “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”;

■ **Súmula Vinculante n. 30:** “é inconstitucional lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos Municípios”.

CUIDADO: o STF, por sugestão do Ministro Dias Toffoli, **suspendeu a publicação** da edição da referida súmula aprovada na sessão de 03.02.2010 (*PSV — Proposta de Súmula Vinculante 41*). Isso porque, conforme noticiado, a proposta de redação aprovada “... restringia a inconstitucionalidade à lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS que seria destinada aos municípios. Mas o ministro Dias Toffoli verificou que há precedentes envolvendo outra situação, que não especificamente o incentivo fiscal. Trata-se de uma lei estadual dispendo sobre processo administrativo fiscal de cobrança e compensação de crédito/débito do particular com o Estado. No caso em questão, houve uma dação em pagamento, em que foram dados bens que não foram repartidos com o município” (*Notícias STF*, 04.02.2012 — **matéria pendente**);

■ **Súmula Vinculante n. 31:** “é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS sobre operações de locação de bens móveis”;

■ **Súmula Vinculante n. 32:** “o ICMS não incide sobre alienação de

salvados de sinistro pelas seguradoras”;

■ **Súmula Vinculante n. 33:** “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4.º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”;

■ **Súmula Vinculante n. 34:** “a Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho — GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005)”;

■ **Súmula Vinculante n. 35:** “a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”;

■ **Súmula Vinculante n. 36:** “compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil”;

■ **Súmula Vinculante n. 37:** “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”; [150](#)

■ **Súmula Vinculante n. 38:** “é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”;

■ **Súmula Vinculante n. 39:** “compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”;

■ **Súmula Vinculante n. 40:** “a contribuição confederativa de que trata o artigo 8.º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”;

■ **Súmula Vinculante n. 41:** “o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”;

■ **Súmula Vinculante n. 42:** “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”;

■ **Súmula Vinculante n. 43:** “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”;

■ **Súmula Vinculante n. 44:** “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

■ **Súmula Vinculante n. 45:** “a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual”;

■ **Súmula Vinculante n. 46:** “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”;

■ **Súmula Vinculante n. 47:** “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”;

■ **Súmula Vinculante n. 48:** “na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro”;

■ **Súmula Vinculante n. 49:** “ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”;

■ **Súmula Vinculante n. 50:** “norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”;

■ **Súmula Vinculante n. 51:** “o reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais”;

■ **Súmula Vinculante n. 52:** “ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”;

■ **Súmula Vinculante n. 53:** “a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados”.

■ 11.14.13. Aspectos conclusivos

A súmula vinculante introduzida pela *Reforma do Judiciário* mostra-se totalmente **constitucional**. Não há falar em engessamento do Judiciário, na medida em que está **prevista a revisão e o cancelamento dos enunciados editados**.

No mais, há de se notar que o STF só editará súmula em relação a matérias e assuntos específicos (conveniência política) e desde que sejam observados os requisitos do art. 2.º, § 1.º, da Lei n. 11.417/2006: que o enunciado da súmula tenha por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciais ou entre estes e a Administração Pública, **controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão**.

No choque entre dois grandes valores fundamentais de igual hierarquia (“colisão de direitos fundamentais”), parece ser mais condizente, diante da realidade forense pátria, a garantia da **segurança jurídica** e do **princípio da igualdade substancial ou material**, em vez da liberdade irrestrita do

magistrado nas causas já decididas e pacificadas no STF, “desafogando”, por consequência, o Poder Judiciário das milhares de causas repetidas.

Conforme apontado no relatório da CCJ do SF, “parece-nos evidente que a súmula vinculante tende a promover os princípios da igualdade e da segurança jurídica, pois padronizará a interpretação das normas, evitando-se as situações propiciadas pelo sistema vigente, em que pessoas em situações fáticas e jurídicas absolutamente idênticas se submetem a decisões judiciais diametralmente opostas, o que prejudica em maior medida aqueles que não têm recursos financeiros para arcar com as despesas processuais de fazer o processo chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde a tese que lhe beneficiaria fatalmente seria acolhida”.

Deve-se deixar bem claro, também, que a PEC, nesses moldes aprovada, não fere a regra do art. 60, § 4.º, III (**cláusula pétrea** da Separação de Poderes). Isso porque a limitação do *poder de reforma* não se restringe à impossibilidade de alteração da matéria definida pela doutrina como “cláusula pétrea”. A regra deve ser lida no sentido de ser vedada não a reforma, mas a reforma “tendente a abolir”.

Reforçada, então, estará a regra da “separação de Poderes” mitigada, nos exatos termos de interferência de um órgão em outro, sem, é claro, esgotar a autonomia natural (“freios e contrapesos”).

Finalmente, nos termos do art. 8.º da EC n. 45/2004, cabe observar que as súmulas que estavam em vigor na data da publicação da EC (quais sejam, as de ns. 1-736) somente produzirão efeito vinculante após sua **confirmação** por 2/3 dos membros do STF e publicação na imprensa oficial.

As súmulas editadas a partir da EC n. 45/2004 ou continuarão a ser meramente **persuasivas** ou serão **vinculantes**. Para que sejam vinculantes, deverão passar pelo procedimento diferenciado definido na lei regulamentadora. Por questões de organização, deverão as súmulas vinculantes, como vem sendo feito e já indicamos, receber uma nova e distinta numeração, iniciando-se pela de n. 1.

■ 11.15. EXTINÇÃO DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA

■ 11.15.1. Histórico nas Constituições

Fazendo uma breve análise, percebe-se que as Constituições de 1824 e de 1891 nada falaram sobre “Tribunais de Alçada” ou sobre “alçada”.

A de 1934, em seu art. 104, § 7.º, estabeleceu que “os Estados poderão criar Juízes com investidura limitada a certo tempo e competência para julgamento das causas de pequeno valor, preparo das excedentes da sua alçada e substituição dos Juízes vitalícios”.

A Constituição de 1937, nos termos de seu art. 106, com praticamente a mesma redação, determinou que “os Estados poderão criar Juízes com investidura limitada no tempo e competência para julgamento das causas de pequeno valor, preparo das que excederem da sua alçada e substituição dos Juízes vitalícios”.

De maneira bastante explícita, pela primeira vez, a de 1946, em seu art. 124, II, permitiu aos Estados a criação de Tribunais de Alçada inferiores aos Tribunais de Justiça.

A de 1967, por seu turno, fixou as regras no art. 136, § 1.º, “a”, e § 3.º: “... § 1.º A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça: a) Tribunais inferiores de segunda instância, com alçada em causas de valor limitado, ou de espécies, ou de umas e outras; (...) § 3.º Compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar os membros do Tribunal de Alçada e os Juízes de inferior instância, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, quando se tratar de crimes eleitorais”. [151](#)

Por derradeiro, a CF/88 fixou, nos termos do art. 96, II, “c”, competir privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169, a “criação ou extinção dos tribunais inferiores”.

No art. 96, III, estabeleceu-se que “o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última

entrância ou, onde houver, no **Tribunal de Alçada**, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso II e a classe de origem”.

■ 11.15.2. O surgimento dos Tribunais de Alçada nos Estados

Percebia-se que, “no maior Tribunal de Apelação do País, em São Paulo, que contava à época com 25 Desembargadores, o número de feitos ascendeu a mais de 6.000, mais do dobro dos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Com base nisso, o *Deputado Plínio Barreto* propôs uma emenda que permitisse aos Estados a criação de Tribunais de Alçada inferior”. [152](#)

Nesse sentido, diante do permissivo do art. 124, II, da CF/46, pioneiramente, com o objetivo de desafogar o TJ, criou-se, por intermédio da Lei estadual n. 1.162, de 31 de julho de 1951, o Tribunal de Alçada de São Paulo, instalado no dia 11 de agosto [153](#) de 1951.

“A denominação Tribunal de Alçada foi inspirada na organização judiciária portuguesa, como explicou o Ministro Mário Guimarães em sua obra *O juiz e a função jurisdicional*, ao observar que assim se chamavam os Tribunais volantes que existiam em Portugal, que, regulados pelas Ordenações Afonsinas, circulavam pelas províncias distribuindo justiça”. [154](#)

O advento da indústria automobilística, aliado ao grande crescimento da sociedade a partir da década de 1960, fez surgir a necessidade de se criarem outros tribunais.

A Lei estadual (SP) n. 9.125, de 19.11.1965, determinou o desdobramento do Tribunal de Alçada da seguinte maneira: **a)** 1.º TAC; **b)** TACRIM (1967); **c)** 2.º TAC (1972). Assim, até 1972, conviviam o TJ, o TAC e o TACRIM, já que a divisão do único Tribunal de Alçada Cível se consolidou em 1972.

Nos outros Estados, observamos o surgimento dos Tribunais de Alçada de Minas Gerais (1965), Paraná (1970), Rio Grande do Sul (1971) e Rio de Janeiro (antigo da Guanabara).

Na data da promulgação da **EC n. 45/2004**, contudo, restavam apenas os

Tribunais de Alçada de São Paulo (1.º TAC, 2.º TAC e TACRIM) e o do Paraná.

■ 11.15.3. AEC n. 45/2004

O art. 4.º da EC n. 45/2004 assim estabeleceu:

“Art. 4.º Ficam **extintos** os tribunais de Alçada, onde houver, passando os seus membros a **integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados**, respeitadas a antiguidade e classe de origem.

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado da promulgação desta Emenda, os Tribunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão a integração dos membros dos tribunais extintos em seus quadros, fixando-lhes a competência e remetendo, em igual prazo, ao Poder Legislativo, proposta de alteração da organização e da divisão judiciária correspondentes, assegurados os direitos dos inativos e pensionistas e o aproveitamento dos servidores no Poder Judiciário estadual”.

No tocante ao Estado de São Paulo, Roberto Solimene anota, em interessante e completo estudo, que “... Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em 29 de dezembro, publicou a **Resolução n. 194/2004**, cujo artigo 1.º declarou integrados no Tribunal de Justiça ‘os Juízes dos extintos Tribunais de Alçada’, ‘no cargo de Desembargador, mediante apostilamento dos títulos’, ato este posterior, veiculado no *Diário Oficial da Justiça* de 5 de janeiro de 2005 (p. 3), sem prejuízo da remessa de projeto de lei à Assembleia Legislativa, em que também se indicava a necessidade de criação de 22 novos cargos de desembargador, mais 836 cargos de assistentes jurídicos e 28 de escreventes, com o fito de dar imediata vazão dos 195.475 processos que aguardavam distribuição no TJ e 289.003 nas casas extintas”. [155](#)

Em relevante crítica, o autor observa que, “de acordo com o artigo 3.º, da já mencionada Resolução n. 194/2004, haverá concurso de remoção interna dos atuais desembargadores paulistas e somente depois é que os Juízes dos Tribunais extintos escolherão as Câmaras que passarão a integrar, sendo plausível a chance

de alguém, que ao longo de muitos anos trabalhou com determinada matéria, passar a julgar processos, daqui por diante, de outra completamente diferente (...). Desperdício de conhecimento e dificuldades de adaptação, afirmam muitos”. [156](#)

Resta aguardar. Parece-nos que, apesar do “gigantismo” em que se transforma a estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo, a reforma é bem-vinda. E vejam que interessante: as necessidades que justificaram e motivaram o surgimento dos Tribunais de Alçada — *agilização da prestação jurisdicional, desafogamento dos Tribunais de Justiça, eficácia na distribuição da Justiça* — são as mesmas para a sua extinção. No mínimo curioso... mas deixemos isso de lado!

■ 11.16. QUESTÕES

1. (Magistratura/SP/171.º) Analise as afirmações abaixo:

- I. O Magistrado só poderá exercer uma função no Magistério se estiver em disponibilidade.
- II. Desde seu ingresso na carreira, o Magistrado só poderá perder seu cargo por sentença judicial transitada em julgado.
- III. Somente poderão ingressar no STF os Ministros que exerceram durante dois anos suas funções no STJ.
- IV. Os Tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, pelo voto da maioria de seus membros ou dos membros do seu órgão especial.

Pode-se afirmar que:

- a) todas as afirmações estão incorretas;
- b) todas as afirmações estão corretas;
- c) apenas as afirmações I e II estão corretas;
- d) apenas a afirmação III está correta.

2. (OAB/SP/107.º) Em relação às garantias da magistratura, é correto afirmar que:

- a) a vitaliciedade é sempre adquirida pelos magistrados após dois anos de exercício no cargo;
- b) a inamovibilidade pode ser afastada por motivo de interesse público;

- c) a irredutibilidade de subsídio torna os juízes imunes à tributação por meio do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
- d) a vitaliciedade impede definitivamente a perda do cargo pelos juízes.

3. (OAB/SP/109.º) Projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça estadual recebeu emenda parlamentar para atribuir remuneração aos Juizes de Paz, matéria não contemplada no projeto original. Aemenda:

- a) funda-se na competência do Poder Legislativo para dispor sobre fixação de remuneração de servidores;
- b) viola a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário;
- c) terá que ser autorizada pelo Tribunal de Justiça;
- d) tem fundamento constitucional, porque a justiça de paz não se insere no quadro da magistratura.

4. (Magistratura/SP/172.º) Os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal são processados e julgados, originariamente:

- a) pelo STJ, nos crimes comuns, e pelos Tribunais de Justiça a que pertençam, nos crimes de responsabilidade;
- b) pelo STF, nos crimes de responsabilidade, e pelo STJ, nos crimes comuns;
- c) pelo STJ, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;
- d) pelo STF, tanto nos crimes comuns, como nos de responsabilidade.

5. (MP/78.º/SP) A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados:

- a) será conhecida e julgada pelo STJ;
- b) será conhecida e julgada pelo Senado Federal;
- c) não será conhecida, pela suspensão que decorre do envolvimento dos julgadores;
- d) será conhecida e julgada pelo Conselho da República;
- e) será conhecida e julgada pelo STF.

6. (Magistratura/SP/171.º) A escolha e a nomeação do advogado para compor o quinto constitucional é da competência:

- a) da Ordem dos Advogados, exclusivamente;
- b) do Poder Executivo e do Poder Judiciário;

- c) da Ordem dos Advogados, do Poder Judiciário e do Poder Executivo;
- d) do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

7. (AFC/CGU/ESAF/2008) Assinale a única opção incorreta relativa ao Poder Judiciário.

- a) São órgãos do Poder Judiciário os Tribunais e Juízes Eleitorais, inclusive as Juntas Eleitorais.
- b) São órgãos do Poder Judiciário os Tribunais e Juízes Militares, inclusive o Tribunal Marítimo.
- c) A participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento do juiz.
- d) A lei pode limitar a presença, em determinados atos dos órgãos do Poder Judiciário, inclusive julgamentos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes.
- e) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, inclusive as disciplinares, que também devem ser tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

8. (AGU — CESPE/UnB — 2010) Com relação às competências do STF, do STJ e da justiça federal, julgue o item seguinte:

O STF reconhece sua competência originária para julgar ação judicial tendo como partes entidade da administração indireta federal, de um lado, e estado-membro, de outro, na hipótese de discussão acerca de imunidade recíproca.

9. (Analista Administrativo MPU — CESPE/UnB — 2010) Julgue o item a seguir, referente ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça:

De acordo com a CF, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas as competências da justiça militar e da justiça eleitoral.

10. (Analista do MPSE — Área Direito — FCC — 2010) Dentre outras, é competência do Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente:

- a) os *habeas data* e os mandados de segurança contra ato de Ministros de Estado ou do próprio Tribunal.

- b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados.
- c) as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais quando a decisão recorrida contrariar lei federal.
- d) o *habeas data* e o mandado de injunção contra ato do Procurador-Geral da República.
- e) os mandados de segurança e de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se concessiva a decisão.

11. (Analista Processual MPU — CESPE/UnB — 2010) No Estado brasileiro, a atuação dos três poderes dá-se de forma harmônica, mas complementar. Acerca dos poderes, do seu funcionamento e dos respectivos integrantes, julgue o item subsequente:

Os Tribunais Regionais Federais podem funcionar de forma descentralizada, constituindo Câmaras regionais, como forma de assegurar a plenitude do acesso à justiça.

12. (Técnico Judiciário do TJ/MG — 2010) Em face da existência do Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais, é CORRETO afirmar que:

- a) se compõe integralmente por oficiais militares.
- b) o efetivo militar do Estado é superior a vinte mil integrantes.
- c) o Tribunal tem competência para julgar recursos envolvendo as polícias das forças armadas.
- d) sua existência decorreu da extinção do Tribunal de Alçada.

13. (TJSE/CESPE-UnB/2008) Assinale a opção correta quanto ao CNJ:

- a) O CNJ pode, apenas mediante provocação em sede recursal, rever os processos disciplinares de juízes julgados há menos de um ano.
- b) O poder de fiscalização do CNJ alcança, além dos magistrados, os serviços auxiliares e até serviços notariais e de registro.
- c) O CNJ não é órgão do Poder Judiciário porque, em sua composição, há indicação de membro do Ministério Público da União, de advogados indicados pela OAB e de dois cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
- d) Compete ao ministro do STF, que integra o CNJ, o exercício das funções de corregedor.
- e) O procurador-geral da República e o presidente da OAB são membros natos do CNJ.

14. (OAB-SP/CESPE/UnB/2008/135.º) O Conselho Nacional de Justiça:

- a) não integra o Poder Judiciário.
- b) tem seus atos sujeitos a controle apenas no STF.
- c) ainda não teve a constitucionalidade da sua instituição apreciada pelo STF.
- d) exerce função jurisdicional em todo o território nacional.

15. (PGE-CE/CESPE/UnB-2008) No referente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinale a opção correta:

- a) O CNJ é órgão do Poder Judiciário com poder jurisdicional em todo o território nacional.
- b) As decisões do CNJ fazem coisa julgada formal e material.
- c) Ao CNJ cabe rever, em grau de recurso, as decisões jurisdicionais dos membros do Poder Judiciário.
- d) Os atos do CNJ estão sujeitos ao controle jurisdicional do STF.
- e) Nos crimes de responsabilidade, os membros do CNJ são julgados perante o STF.

16. (Procurador do MP junto ao TCE/RO — FCC/2010) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

- a) é órgão fiscalizador da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário e dos órgãos que desempenham funções essenciais à Justiça previstos na Constituição.
- b) não integra a estrutura do Poder Judiciário para que possa exercer, com isenção, a atividade de controle externo das atividades jurisdicionais.
- c) é composto por quinze membros, com mandato de quatro anos, não admitida a recondução, sendo o seu Presidente o mesmo do STF.
- d) é integrado por conselheiros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
- e) tem competência para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União.

17. (Exame da OAB Unificado 2010.2 — FGV) A respeito do Conselho Nacional de Justiça é correto afirmar que:

- a) é órgão integrante do Poder Judiciário com competência administrativa e jurisdicional.
- b) pode rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano.
- c) seus atos sujeitam-se ao controle do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de

Justiça.

- d) a presidência é exercida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal que o integra e que exerce o direito de voto em todas as deliberações submetidas àquele órgão.

18. (MPE/PR-2008) Analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta:

- I. o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão da maioria absoluta dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário;
 - II. compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;
 - III. funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o Conselho da Justiça Federal;
 - IV. o Supremo Tribunal Federal é composto por onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada;
 - V. compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.
- a) apenas as assertivas I, IV e V estão corretas;
 - b) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas;
 - c) apenas as assertivas I, II e V estão corretas;
 - d) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas;
 - e) apenas as assertivas II, III e V estão corretas.

19. (Analista Judiciário TRT 17.^a Região/ES UnB/CESPE — 2009) Conforme entendimento do STF, compete à Justiça do Trabalho apreciar litígios instaurados contra entidades de previdência privada e relativos à complementação de aposentadoria, pensão ou de outros benefícios previdenciários, desde que a controvérsia jurídica resulte de obrigação oriunda de contrato de trabalho.

20. (OAB 137.^a CESPE/UnB — 2009) De acordo com dispositivo constitucional vigente, a súmula com efeito vinculante:

- a) será editada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a correta interpretação de lei federal.
- b) será editada por qualquer tribunal, quando houver reiteradas decisões que recomendem a uniformização do entendimento pelos juízes de primeiro grau.
- c) será editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após reiteradas decisões sobre matéria constitucional.
- d) será editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o aprimoramento das rotinas administrativas dos órgãos do Poder Judiciário.

21. (MP/MA — 2009) No tocante à “súmula vinculante”:

- a) podem editá-la o STF e STJ, mediante aprovação de dois terços de seus membros, e ao seu conteúdo estarão vinculados não só os órgãos do Poder Judiciário como também os da administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal;
- b) pode editá-la apenas o STF, mediante aprovação de dois terços (2/3) de seus membros e ao seu conteúdo também estará vinculada a administração pública direta e indireta;
- c) pode editá-la apenas o STJ, mediante aprovação de dois terços de seus membros e ao seu conteúdo estarão vinculados apenas os órgãos do Poder Judiciário.
- d) podem editá-la o STF e o STJ, mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros e ao seu conteúdo estarão vinculados os órgãos do Poder Judiciário;
- e) pode ser editada pelo STF, mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros.

22. (Exame da OAB Unificado 2010.2 — FGV) Em relação à inovação da ordem constitucional que instituiu a nominada Súmula Vinculante, é correto afirmar que:

- a) somente os Tribunais Superiores podem editá-la.
- b) podem ser canceladas, mas vedada a mera revisão.
- c) a proposta para edição da Súmula pode ser provocada pelos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade.
- d) desde que haja reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, aprovar a Súmula mediante decisão da maioria absoluta de seus membros.

23. (Advogado — Caixa — CESGRANRIO/2012) A súmula vinculante n. 13, ao reconhecer que a prática do nepotismo viola a Constituição da República, impede a contratação de parentes de autoridades e de funcionários para cargos de confiança e de comissão:

- a) somente no âmbito do Poder Executivo;
- b) somente no âmbito do Poder Judiciário;
- c) somente no âmbito dos Poderes Executivo e Judiciário;
- d) somente no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo;
- e) no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

24. (Promotor de Justiça — MPE-GO/2012) Sobre o instituto da Súmula Vinculante, assinale a alternativa correta:

- a) revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, opera-se sua caducidade automática;
- b) o uso da reclamação contra omissão ou ato da administração pública que se mostre contrário ao teor de enunciado de súmula vinculante só será admitido após o esgotamento das vias administrativas;
- c) a todo e qualquer interessado é dado propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante;
- d) somente os legitimados ativos ao ajuizamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante.

25. (6.º Concurso Público de Outorga de Delegações de Notas e de Registro/TJSP — 2009) É integrante do Poder Judiciário o:

- a) Tribunal de Contas.
- b) Juiz Militar.
- c) Juiz de Paz.
- d) Ministro da Justiça.

26. (Oficial de Justiça SP/VUNESP — 2009) A competência dos Tribunais dos Estados será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do:

- a) Tribunal de Justiça.
- b) Governador do Estado.
- c) Legislativo Estadual.
- d) Supremo Tribunal Federal.
- e) Superior Tribunal de Justiça.

27. (Procurador do Estado/AM/FCC/2010) A Constituição Federal, ao disciplinar o regime dos precatórios judiciais, determina que:

- a) as condenações judiciais de natureza alimentar não estão sujeitas a pagamento por precatório, qualquer que seja seu valor.
- b) as condenações judiciais em favor de pessoas com mais de sessenta anos não estão sujeitas a pagamento por precatório, qualquer que seja seu valor.
- c) é vedado o fracionamento do valor do precatório em qualquer hipótese.
- d) o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor.
- e) é vedada a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federativo.

28. (Analista Judiciário — TJ/PE — FCC/2012) Hércules, Presidente do Tribunal de Justiça, visando beneficiar seu filho Abrão, burlou a ordem cronológica e retardou a liquidação regular do precatório de Otávio. Nesse caso, Hércules incorreu em:

- a) ilícito administrativo e responderá perante a Assembleia Legislativa do respectivo Estado.
- b) ilícito administrativo e responderá perante a Corregedoria do respectivo Tribunal.
- c) crime comum e responderá perante o Órgão Especial do respectivo Tribunal.
- d) crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.
- e) crime comum e responderá perante a Assembleia Legislativa do respectivo Estado.

29. (Técnico Judiciário — TRT11 — Área Administrativa — FCC/2012) Paulo é Juiz do Trabalho em certa comarca. Xisto é Juiz de um Tribunal Regional do Trabalho de determinada região. Para Paulo e Xisto comporem o Conselho Nacional de Justiça, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, eles deverão ser indicados:

- a) pelo Presidente do Senado Federal.
- b) pela maioria absoluta de todos os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil.
- c) pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) pelo Tribunal Superior do Trabalho.
- e) pelo Congresso Nacional.

30. (Auditor Fiscal da Receita Estadual — SEFAZ-RJ — FGV/2011) As sucessivas reformas da Constituição atingiram a estrutura do Poder Judiciário nacional. No curso do debate, houve acerba campanha, inclusive da OAB, pela instituição do controle externo da atuação dos juízes. Após os debates, surgiram os novos órgãos: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Nessa linha, é correto afirmar que:

- a) o CNJ exerce o controle externo da atividade do Poder Judiciário.
- b) os dois Conselhos referidos integram a estrutura do Poder Judiciário.
- c) é órgão integrante do Poder Judiciário o CNJ, exercendo controle interno.
- d) o CNMP exerce a atividade de controle externo do Poder Judiciário.
- e) o Poder Judiciário não possui controle administrativo interno previsto.

31. (Analista Judiciário — Execução de Mandados — STM — CESPE/UnB/2011) O CNJ é órgão administrativo do Poder Judiciário ao qual compete o controle da atuação administrativa e financeira desse poder, e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, estabelecendo constitucionalmente, porém de forma exemplificativa, suas mais importantes atribuições, que poderão ser acrescidas pelo Estatuto da Magistratura.

32. (Procurador da AL/ES — CESPE/UnB/2011) Assinale a opção correta no que concerne ao Poder Judiciário:

- a) Compete ao Presidente da República nomear todos os membros do CNJ após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
- b) O STF deverá extinguir o feito quando reconhecer sua incompetência para processar e julgar a demanda.
- c) Compete ao STF julgar as ações populares ajuizadas contra o Presidente da República.
- d) A garantia da vitaliciedade admite relativização, já que os ministros do STF podem perder o cargo em virtude de condenação por crime de responsabilidade, mediante decisão do Senado Federal, sem a necessidade de decisão transitada em julgado emanada do Poder Judiciário.
- e) O CNJ é órgão do Poder Judiciário desprovido de função jurisdicional cujas competências constam de rol taxativo previsto na CF.

33. (Analista Judiciário TRT1 — Área Administrativa — FCC/2013) De acordo com as competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal:

- a) não lhe cabe julgar recursos interpostos contra acórdãos que versem sobre direito do trabalho.
- b) não lhe cabe julgar a inconstitucionalidade de leis municipais em face da Constituição Federal, ainda que incidentalmente no processo.
- c) não lhe cabe julgar a reclamação por violação à súmula vinculante que verse sobre direito do trabalhador previsto na Constituição Federal.
- d) cabe-lhe julgar os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais.
- e) cabe-lhe julgar o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, salvo se a ação visar ao exercício de direito trabalhista assegurado na Constituição.

34. (Técnico Judiciário — TRE/RJ — Área Administrativa — CESPE/UnB/2012) Com relação ao Poder Judiciário, julgue o item seguinte:

O presidente do Supremo Tribunal Federal exerce também a presidência do Conselho Nacional de Justiça.

35. (AGU — Advogado — CESPE/UnB/2012) No que se refere ao estatuto constitucional da magistratura e às competências do STF, julgue o item subsequente:

A CF veda aos juízes que se aposentarem ou forem exonerados o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram até o decurso de três anos após o desligamento.

36. (STJ — Todos os Cargos — Conhecimentos Básicos — CESPE/UnB/2012) Em relação ao Poder Judiciário, julgue o item seguinte:

O Conselho da Justiça Federal, que funciona junto ao STJ, tem competência para exercer a supervisão administrativa e orçamentária da justiça federal tanto de primeiro quanto de segundo grau de jurisdição.

37. (Auditor de Controle Externo — TC/DF — CESPE/UnB/2012) Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário:

A regra do quinto constitucional se aplica aos tribunais regionais federais, aos tribunais dos estados, ao TJDF e aos tribunais do trabalho.

38. (Especialista/DEPEN — CESPE/UnB/2013) A propósito do Poder Judiciário,

julgue o próximo item.

Apesar de competir ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o texto constitucional não reconhece esse órgão como integrante do Poder Judiciário.

39. (Defensoria Pública/DF — CESPE/UnB/2013) Julgue o item a seguir, que versa sobre o Poder Judiciário, o MP e a DP, conforme o disposto na CF:

A regra constitucional que proíbe o magistrado de exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual se tenha afastado, antes de decorrido o período de três anos, contados do afastamento do cargo, aplica-se tanto ao Poder Judiciário estadual quanto ao federal de qualquer instância, incluindo-se o STF, o STJ e os demais tribunais superiores.

40. (Analista MPU — CESPE/UnB/2013) Julgue o próximo item, relativo a Poder Judiciário e funções essenciais à justiça:

Considere que determinado sindicato pretenda ajuizar ação possessória para garantir o livre-acesso de empregados e clientes às agências bancárias, fechadas devido à greve realizada por empregados de um banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para julgar a ação é da justiça comum estadual, por tratar de matéria concernente ao direito civil.

41. (Analista Judiciário/CNJ — CESPE/UnB/2013) Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir:

A inamovibilidade constitui garantia que é deferida apenas aos juízes titulares, não alcançando os substitutos.

42. (Analista Judiciário/CNJ — CESPE/UnB/2013) Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir:

As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não estarão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.

■ GABARITO ■

- | |
|---|
| 1. “a”. A afirmação “I” está errada porque para exercer a função de magistério não é necessário |
|---|

que esteja em disponibilidade (art. 95, parágrafo único, I); “II” — o erro está no fato de o magistrado, durante o estágio probatório (nos dois primeiros anos), poder perder o cargo por deliberação do tribunal a que estiver vinculado; “III” — o art. 101 não prevê o requisito de exercício de funções previamente no STJ; “IV” — a declaração de inconstitucionalidade dar-se-á pelo voto da <i>maioria absoluta</i> e não somente simples, como aludido na questão (cf. art. 97).
2. “b”. Cf. art. 95, II, combinado com o art. 93, VIII. No exame 115.º houve questionamento idêntico a este. Isso mostra ser extremamente importante completar o estudo teórico com a análise dos testes. O candidato que tivesse analisado essa questão do exame 107.º da OAB certamente já teria um ponto garantido!!! E não podemos esquecer que, pela EC n. 45/2004, o reconhecimento do interesse público, nos termos do art. 93, VIII, dá-se, por meio do <i>quorum</i> de maioria absoluta e não mais 2/3!
3. “b”. Cf. arts. 2.º, 96, II, “b”, 63, II (c/c o art. 25), 99 e 169.
4. “c”. Cf. art. 105, I, “a” (<i>vide</i> sistematização sobre competência para processar e julgar crimes de responsabilidade no <i>item 10.4.15</i>).
5. “e”. Art. 102, I, “n”.
6. “c”. Cf. art. 94 da CF/88.
7. “b”. Cf. arts. 92 e 93 da CF/88, sendo que não há a previsão no art. 92 de “tribunais marítimos”.
8. “certo”. Art. 102, I, “f”.
9. “certo”. Art. 109, IV. Como se percebe, a prova exigia o conhecimento da “letra da lei”; portanto, insistimos, memorizem as competências dos Tribunais, previstas nos arts. 102 (STF), 105 (STJ), 108 (TRF), 109 (Juízes Federais), 114 (Justiça do Trabalho) etc., bem como do CNJ (art. 103-B, § 4.º, I-VII e § 5.º, I-III) e do CNMP (art. 130-A, § 2.º, I-V e § 3.º, I-III).
10. “a”. Art. 105, I, “b”. A letra “b” de fato estabelece competência do STJ, conforme art. 105, II, “b”. Contudo, além de ter faltado a especificação de que o julgamento seria apenas na hipótese de ser denegatória a decisão, não se trata de julgamento originário (como pede a questão), mas de julgamento em sede de recurso ordinário. No mesmo sentido, a letra “c” não estabelece competência originária, mas hipótese de recurso especial (art. 105, III, “a”). A letra “d” está errada

porque, muito embora, de fato, a competência para o julgamento de MI contra ato (omissivo) do PGR seja do STJ (art. 105, I, “h”, e <i>MI 2-QQ</i>, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 13.10.88, Plenário, <i>DJ</i> de 24.02.1989), a competência para o julgamento de <i>habeas data</i> contra ato do PGR é do STF (art. 102, I, “d”), e não do <i>STJ</i>. Finalmente, a letra “e” está errada por 2 motivos: a) primeiro, a competência para julgamento de MS e MI decidido em única instância pelos Tribunais Superiores seria do STF; b) segundo, nessa hipótese, deveria ser denegatória a decisão (art. 102, II, “a”).
11. “certo”. Art. 107, § 3.º.
12. “b”. Art. 125, § 3.º. A letra “a” está errada, uma vez que, conforme visto na parte teórica, o julgamento na Justiça Militar é marcado pelo escabinato, ou seja, por um colegiado formado por 1 juiz togado e 4 juízes leigos, no caso, por Oficiais Militares e, assim, o TJM não se compõe integralmente por oficiais militares. A letra “c” está errada, na medida em que o julgamento das forças armadas — Marinha, Exército e Aeronáutica — se dá pela Justiça Militar da União, e não pela Justiça Militar Estadual. Esta tem competência para o julgamento dos militares estaduais, não julgando civis (diferentemente da Justiça Militar da União, que tem competência para, nas hipóteses previstas em lei, julgar civis — <i>vide</i> parte teórica). Finalmente, a letra “d” está errada, pois não há nenhuma relação entre a extinção de Tribunal de Alçada e a Justiça Militar.
13. “b”. Art. 103-B, § 4.º, III, da CF/88.
14. “b”. A letra “a” está errada por violar o art. 92, I-A. A letra “c” é falsa, pois a instituição do CNJ, conforme vimos na parte teórica, já foi reconhecida pelo STF como constitucional (ADI 3.367). Por fim, a “d” é errada, pois o CNJ não exerce função jurisdicional, mas, como visto, meramente administrativa.
15. “d”. Conforme estudado na parte teórica, o CNJ é órgão de natureza exclusivamente administrativa, com atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Portanto, errada a letra “a”. A letra “b” está errada, pois as decisões do CNJ podem ser revistas pelo STF (art. 102, I, “r”). Assim, errada a letra “b” e correta a letra “d”. O CNJ não é órgão recursal (no âmbito jurisdicional). Por fim, os membros do CNJ são julgados pelo Senado Federal no caso de crime de responsabilidade (art. 52, II).
16. “e”. Art. 103-B, § 4.º, II. A letra “a” está errada, pois a atuação do CNJ se dá em relação ao Poder Judiciário, e não sobre os órgãos que desempenham funções essenciais à Justiça, que têm controle próprio, como o CNMP (<i>Ministério Público</i>), a OAB (<i>Advocacia</i>) etc. A letra “b” está errada, pois o CNJ é órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 92, I-A. A letra “c” está errada,

uma vez que o mandato dos membros do CNJ é de 2 anos, admitida uma recondução (art. 103-B, <i>caput</i>). A letra “d” está errada, na medida em que a sabatina dos Conselheiros (exceto do Presidente do CNJ, que é membro nato e, portanto, não é sabatinado) se implementa pela maioria absoluta do SF, e não do CN (art. 103-B, § 2.º).
17. “b”. Art. 103-B, § 4.º, V. A letra “a” está errada, pois a competência do CNJ, conforme visto na parte teórica, restringe-se ao âmbito administrativo. A letra “c” está errada porque o STJ não tem competência sobre os atos do CNJ. A competência é do STF (art. 102, I, “r”). A letra “d” está errada, pois, de acordo com a EC n. 61/2009, é membro do CNJ não o Ministro do STF, mas, sim, o Ministro Presidente do STF, na condição de membro nato.
18. “e”.
19. “certa”. Cf. CC 7.500.
20. “c”. Art. 103-A da CF/88.
21. “b”. Art. 103-A da CF/88.
22. “c”. Art. 103-A, § 2.º.
23. “e”.
24. “b”.
25. “b”.
26. “a”. Art. 125, § 1.º, da CF/88.
27. “d”. Art. 100, § 13. A letra “a” está errada, já que, por regra, também, os débitos de natureza alimentar devem ser pagos por precatório, conforme, inclusive, S. 655/STF. As letras “b” e “c” estão erradas por violarem o art. 100, § 2.º. A letra “e” está errada por violar o art. 100, § 11, que admite, nos seus termos, a entrega de precatórios.
28. “d”, nos termos da literalidade do art. 100, § 7.º, da CF/88. Assim, não deixem de estudar, também, a “letra da lei”.
29. “d”. Conferir quadro no <i>item 11.13.1</i> .

30. “c”.
31. “certo”. Art. 103-B, § 4.º, da CF/88.
32. “d”. Art. 52, II, da CF/88.
33. “d”, art. 102, I, “o”.
34. “certo”, art. 103-B, § 1.º.
35. “certo”. Trata-se da denominada “quarentena de saída”, introduzida pela EC n. 45/2004, no art. 95, parágrafo único, V.
36. “certo”. Cf. art. 105, parágrafo único, II.
37. “certo”. Cf. <i>item 11.7</i> .
38. “errado”. Cf. art. 92, I-A.
39. “certo”. Trata-se da denominada “quarentena de saída”, nos termos do art. 95, parágrafo único, V.
40. “errado”, por violar a SV 23/STF, que interpretou o art. 114, II: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.
41. “errado”. Cf. <i>item 11.5.2.1.2</i> e MS 27.958.
42. “certo”. Cf. <i>item 11.13.5.4</i> .

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

■ 12.1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Com o objetivo de dinamizar a atividade jurisdicional, o poder constituinte originário institucionalizou atividades profissionais (públicas e privadas), atribuindo-lhes o *status* de **funções essenciais à Justiça**, tendo estabelecido suas regras nos arts. 127 a 135 da CF/88: **Ministério Público** (arts. 127 a 130), **Advocacia Pública** (arts. 131 e 132), **Advocacia** (art. 133) e **Defensoria Pública** (art. 134).

■ 12.2. MINISTÉRIO PÚBLICO

■ 12.2.1. Histórico

■ 12.2.1.1. Origens remotas

Há muita divergência doutrinária sobre o surgimento do Ministério Público, chegando alguns a apontar a sua forma inicial há mais de quatro mil anos, na figura do *magiaí*, funcionário real no *Egito Antigo*, que tinha o dever de proteger os cidadãos do bem e reprimir, castigando, os “rebeldes”.

Outros, ainda, identificam o surgimento do Ministério Público na *Antiguidade Clássica*, na *Idade Média* ou até no *direito canônico*.

Divergências à parte, a maioria da doutrina aceita, com mais tranquilidade, o seu surgimento na figura dos **Procuradores do Rei** do *direito francês* (*Ordenança* de 25.03.1302, de Felipe IV, “o Belo”, Rei da França), que prestavam o mesmo juramento dos juízes no sentido de estarem proibidos de exercer outras funções e patrocinar outras causas, senão as de interesse do Rei.

Como bem expõe Mazzilli, “a Revolução Francesa estruturou mais adequadamente o Ministério Público, enquanto instituição, ao conferir garantias a seus integrantes. Foram, porém, os textos napoleônicos que instituíram o Ministério Público que a França veio a conhecer na atualidade. Inegável é a influência da doutrina francesa na história do Ministério Público, tanto que, mesmo entre nós, ainda se usa frequentemente a expressão *parquet*, para referir-se à instituição”.¹

Não obstante a influência francesa, temos de ressaltar a importância do **direito português** sobre a origem do Ministério Público no Brasil, notadamente as *Ordenações Afonsinas* (1447), *Manuelinas* (1514) e *Filipinas* (1603).

Conforme anotam Araujo e Nunes Jr., “no Brasil, fazendo menção ao *Procurador dos Feitos da Coroa* e ao *Promotor de Justiça*, o Alvará de 7 de março de 1609, que criou o Tribunal de Relação da Bahia, foi a primeira legislação a abordar a função de Ministério Público”.²

Passemos, então, a analisar a evolução do Ministério Público especialmente nas Constituições brasileiras, destacando-se, no quadro abaixo, a sua previsão “topológica” (em termos de disposição no texto constitucional), chegando ao *coroamento* na CF/88, pela qual se instituiu total **desvinculação** dos Poderes, declarando ser **instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado**, incumbindo-lhe a **defesa** da **ordem jurídica**, do **regime democrático** e dos **interesses sociais e individuais indisponíveis**, com **autonomia funcional, administrativa e financeira**.

CONSTITUIÇÕES	PREVISÃO TOPOLÓGICA

■ 1824	■ não fez menção ao MP , mas apenas ao <i>Procurador da Coroa e Soberania Nacional</i>
■ 1891	■ previsão muito tímida , disciplinando apenas regras para a designação do PGR, dentre membros do STF e, assim, a alocação dentro do <i>título</i> do Poder Judiciário
■ 1934	■ posicionamento fora dos Poderes , adquirindo <i>status</i> constitucional e estabelecido como órgão de cooperação nas atividades governamentais
■ 1937	■ retrocesso durante o período ditatorial. Tratamento esparso e vago com algumas regras sobre o PGR no <i>capítulo</i> do Poder Judiciário
■ 1946	■ redemocratização. Avanço. Previsão em título especial e próprio , distinto dos Poderes e, assim, não estando atrelado a nenhum deles
■ 1967	■ novamente a previsão do MP, retrocedendo o texto anterior que lhe dava <i>título especial</i> , foi estabelecida no capítulo do Poder Judiciário
■ EC n. 1/69	■ alterando o texto anterior, houve o posicionamento do MP no capítulo do Poder Executivo
■ 1988	■ o MP chega fortalecido no novo ordenamento, ganhando previsão em título próprio, desatrelado dos Poderes e como uma das funções essenciais à Justiça

■ 12.2.1.2. Constituição de 1824

Apesar de não haver menção ao Ministério Público no texto do Império, o seu art. 48 fez a previsão do **Procurador da Coroa e Soberania Nacional**, que tinha a atribuição de **acusação** nos crimes que não pertencessem à Câmara dos Deputados.

Durante o Império, contudo, algumas leis fizeram referência mais específica ao *Promotor Público*, destacando-se, dentre outros:

■ **1830** — *Código Criminal*: no art. 132, falava-se em atribuição de **acusação** do **Promotor** para os crimes ali especificados;

■ **1832** — *Código do Processo Criminal*: em diversas passagens se fez previsão do **Promotor Público**. Dentre outras atribuições, no seu art. 37, § 1.º, estava prevista a de denunciar os crimes públicos e policiais e acusar os delinquentes perante os jurados, assim como os crimes de reduzir à escravidão pessoas livres, cárcere privado, homicídio, ou a tentativa dele, ou ferimentos, com as qualificações dos arts. 202, 203 e 204 do Código Criminal; e roubos, calúnias, injúrias contra o Imperador, membros da Família Imperial, contra a Regência e cada um de seus membros, contra a Assembleia Geral e contra cada uma das Câmaras.

■ 12.2.1.3. Constituição de 1891

Antes mesmo da Constituição de 1891, a partir da *Proclamação da República*, o **Decreto n. 848, de 11.10.1890**, ao organizar a *Justiça Federal*, fez menção ao **Ministério Público**, pela primeira vez, como **instituição**. Vejamos:

■ **1890** — *art. 22 do Decreto n. 848*: ao tratar do *Ministério Público*, destacou a atuação do **Procurador-Geral da República**, competindo-lhe: **a) exercer a ação pública e promovê-la** até o final em todas as causas da competência do Supremo Tribunal; **b) funcionar como representante da União**, e em geral officiar e “dizer de direito” em todos os feitos submetidos à jurisdição do Supremo Tribunal; **c) velar pela execução das leis, decretos e regulamentos que devem ser aplicados pelos juízes federais; d) defender a**

jurisdição do Supremo Tribunal e a dos demais juízes federais; **e)** fornecer instruções e conselhos aos procuradores seccionais e resolver consultas destes, sobre matéria concernente ao exercício da Justiça Federal.

A **Constituição de 1891**, por sua vez, de maneira muito tímida, tratou do Procurador-Geral da República, na *Seção III do Título I*, que disciplinava o **Poder Judiciário**.

Essa previsão topológica tinha uma razão de ser. De acordo com o art. 58, § 2.º, o *Procurador-Geral da República* era designado pelo Presidente da República **dentre os membros do Supremo Tribunal Federal**.

De modo geral, as atribuições do **PGR** deveriam ser definidas na **lei**, havendo apenas uma previsão na Constituição, qual seja, a possibilidade de requerer, de ofício e a qualquer tempo, a **revisão criminal** (art. 81).

■ 12.2.1.4. Constituição de 1934

Na **Constituição de 1934**, o Ministério Público adquire verdadeiro **status constitucional**, não tendo sido a sua previsão atrelada ao Judiciário (conforme o texto de 1891), mas como **órgão de cooperação nas atividades governamentais** (*Seção I do Capítulo VI do Título I*), destacando-se as seguintes regras (arts. 95 a 98):

■ **Organização por lei:** o Ministério Público era organizado na *União*, no *Distrito Federal* e nos *Territórios* por **lei federal**, e, nos *Estados*, pelas **leis locais**.

■ **PGR — nomeação sem a necessidade de fazer parte do Judiciário:** o *Chefe do MPF* nos Juízos comuns era o *Procurador-Geral da República*, de **nomeação do Presidente da República**, com *aprovação do Senado Federal (sabatina)* dentre cidadãos com os requisitos estabelecidos para os *Ministros da Corte Suprema*.

■ **Remuneração e demissão *ad nutum*:** em termos de remuneração, o

PGR tinha os mesmos vencimentos dos **Ministros da Corte Suprema**, sendo, porém, **demissível *ad nutum***.

■ **Chefes do Ministério Público no Distrito Federal e nos Territórios:** referidos Chefes eram de *livre nomeação do Presidente da República* dentre juristas de **notável saber e reputação ilibada**, alistados eleitores e maiores de 30 anos, com os vencimentos dos Desembargadores.

■ **Concurso público e estabilidade:** os membros do Ministério Público Federal que serviam nos Juízos comuns eram nomeados mediante **concurso** e só perdiam os cargos, nos termos da lei, por **sentença judiciária**, ou **processo administrativo**, no qual lhes era assegurada ampla defesa.

■ **Comunicação de decisão ao Senado Federal na hipótese de inconstitucionalidade:** o PGR tinha, ainda, a atribuição de, quando a Corte Suprema declarasse inconstitucional qualquer dispositivo de lei ou ato governamental, comunicar a decisão ao **Senado Federal** para os fins do art. 91, n. IV, e bem assim à autoridade legislativa ou executiva de que tivesse emanado a lei ou o ato.

■ **ADI interventiva:** conforme já estudamos, a ADI interventiva surgiu no texto de 1934, tendo por exclusivo legitimado o **PGR**.

■ **Outras atribuições:** de modo geral, as atribuições do Ministério Público estavam previstas em **lei**. Houve, contudo, além das já mencionadas: **a)** a possibilidade de requerer a revisão dos processos findos em matéria criminal, inclusive os militares e eleitorais; **b)** a competência para interpor recurso extraordinário na Corte Suprema contra as causas decididas pelas Justiças locais em única ou última instância quando ocorresse diversidade de interpretação definitiva da lei federal entre Cortes de Apelação de Estados diferentes, inclusive do Distrito Federal ou dos Territórios, ou entre um destes Tribunais e a Corte Suprema, ou outro Tribunal federal.

■ **Impedimentos dos Procuradores-Gerais:** os Chefes do Ministério Público na União e nos Estados não podiam exercer qualquer outra função

pública, **salvo o magistério** e os **casos previstos na Constituição**, sob pena de perda do cargo.

■ **Previsão de MP Militar e Eleitoral:** o Ministério Público, nas Justiças Militar e Eleitoral, era organizado por leis especiais, e tinha na Justiça Eleitoral as incompatibilidades que referidas leis especiais prescrevessem.

■ **Regra do “quinto constitucional”:** nos termos do art. 104, § 6.º, da Constituição, na composição dos **Tribunais superiores** eram reservados lugares, correspondentes a **1/5** do número total, para serem preenchidos por advogados, ou **membros do Ministério Público** de notório merecimento e reputação ilibada, escolhidos de lista tríplice, organizada na forma do § 3.º.

■ 12.2.1.5. *Constituição de 1937*

Durante a *Ditadura de Getúlio Vargas* houve total retrocesso em relação ao Ministério Público enquanto instituição, havendo tratamento esparso e vago na Constituição, destacando-se:

■ **Procurador-Geral da República:** o PGR era o Chefe do Ministério Público Federal e funcionava junto ao STF (a previsão topológica foi dentro do *capítulo* do “Poder Judiciário”). O PGR era de **livre nomeação e demissão do Presidente da República**, devendo recair a escolha em pessoa que reunisse os requisitos exigidos para Ministro do Supremo Tribunal Federal.

■ **Recurso ordinário:** houve a previsão de o Ministério Público poder interpor **recurso ordinário** nas hipóteses de decisões de última ou única instância denegatórias de *habeas corpus*.

■ **Regra do “quinto constitucional”:** na composição dos *Tribunais superiores*, **1/5** dos lugares era preenchido por advogados ou **membros do Ministério Público**, de notório merecimento e reputação ilibada, organizando o Tribunal de Apelação uma lista tríplice.

■ **Representação da Fazenda Pública:** o art. 109, parágrafo único, estabeleceu que a lei regularia a competência e os recursos nas ações para a **cobrança da dívida ativa da União**, podendo cometer ao **Ministério Público dos Estados** a função de **representar em Juízo a Fazenda Federal**.

■ **Crime comum e de responsabilidade:** a Carta estabeleceu que o **PGR** seria processado e julgado pelo STF nas hipóteses de crime comum e de responsabilidade.

■ **12.2.1.6. Constituição de 1946**

Com a redemocratização o Ministério Público ganha especial destaque na **Constituição de 1946**, disciplinado em **título especial** (o *Título III*, separado dos Poderes e tratando, exclusivamente, da carreira do MP). São as seguintes e principais regras:

■ **Tribunal Federal de Recursos (TFR) e “regra do terço” (art. 103, caput):** o **TFR**, com sede na Capital federal, era composto de 9 Juizes, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo **Senado Federal**, sendo 2/3 entre magistrados e 1/3 entre advogados e **membros do Ministério Público**, com os requisitos do art. 99.

■ **Regra do “quinto constitucional” em âmbito estadual (art. 124, V):** na composição de qualquer **Tribunal estadual**, 1/5 dos lugares era preenchido por advogados e **membros do Ministério Público**, de notório merecimento e reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de prática forense. Para cada vaga, o Tribunal, em sessão e escrutínio secretos, votava lista tríplice. Escolhido um membro do Ministério Público, a vaga seguinte era preenchida por advogado;

■ **MPU organizado por lei (art. 125):** a organização do Ministério Público da União, junto à Justiça Comum, à Militar, à Eleitoral e à do Trabalho se dava por meio de **lei**. Posteriormente, a *EC n. 16/65* estabeleceu que a lei

organizaria o Ministério Público da União junto aos órgãos judiciários federais.

■ **PGR — Chefe do MPF (art. 126):** o PGR era o Chefe do Ministério Público federal. O Procurador, nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo **Senado Federal**, dentre cidadãos com os requisitos indicados no artigo 99, era **demissível *ad nutum***.

■ **Representação da União (art. 126, parágrafo único):** a **União** era **representada em Juízo** pelos **Procuradores da República**, podendo a lei cometer esse encargo, nas Comarcas do interior, ao **Ministério Público local**.

■ **Regra do concurso público e as garantias da estabilidade e da inamovibilidade (art. 127):** os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios ingressavam nos cargos iniciais da carreira mediante concurso. Após **2 anos** de exercício, não podiam ser demitidos senão por **sentença judiciária** ou **mediante processo administrativo**, sendo-lhes facultada a ampla defesa. Outra garantia era a **inamovibilidade**, a não ser mediante representação motivada do Chefe do Ministério Público, com fundamento em conveniência do serviço.

■ **MP em âmbito estadual — carreira (art. 128):** nos Estados, o Ministério Público será também organizado em carreira, observados os preceitos do art. 127 e mais o princípio de **promoção** de entrância a entrância.

■ **EC n. 16/1965:** referida emenda trouxe importantes previsões, por exemplo: **a)** conforme já estudado no capítulo sobre *controle*, referida emenda instituiu, pela primeira vez no direito brasileiro, o sistema de controle concentrado, por meio de representação a ser ajuizada exclusivamente pelo Procurador-Geral da República; a antiga “regra do terço” para a composição foi alterada em relação ao TFR. Pela nova regra, o TFR passou a ser composto de 13 juízes, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo 8 dentre magistrados e **5**

dentre advogados e **membros do Ministério Público**, todos com os requisitos do art. 99.

■ **Crime comum (STF) e de responsabilidade (Senado Federal):** inovando, mantendo a previsão de julgamento do PGR por crime comum no STF (art. 101, I, “b”), a Constituição estabeleceu que o julgamento por crime de responsabilidade seria de competência do Senado Federal (art. 62, II).

■ **12.2.1.7. Constituição de 1967**

De modo geral, todas as regras estabelecidas no texto de 1946 foram repetidas na Constituição de 1967, como as referentes ao *concurso público*, *estabilidade*, *inamovibilidade* etc.

O art. 138, § 2.º, conservou a previsão de que a União seria representada em Juízo pelos **Procuradores da República**, podendo a lei cometer esse encargo, nas Comarcas do interior, ao **Ministério Público local**.

A grande distinção foi a alocação topográfica, com inegável retrocesso, já que não mais prevista a carreira do MP em título especial e exclusivo.

A Constituição de 1967 inseriu o Ministério Público **dentro do capítulo do Poder Judiciário**, na *Seção IX do Capítulo VIII*.

■ **12.2.1.8. Emenda Constitucional n. 1/69**

A **EC n. 1/69** manteve o Ministério Público atrelado aos Poderes. Contudo, em vez de inseri-lo em seção dentro do capítulo do Judiciário, como fazia a Constituição de 1967, fixou a carreira do MP no **capítulo do Poder Executivo** (*Seção VIII do Capítulo VII*), tendo referida alocação permanecido na **EC n. 7/77**.

Basicamente, todas as regras em relação ao *concurso público*, *estabilidade*, *inamovibilidade*, *Chefia do MPF pelo PGR*, *participação no TFR*, “*regra do quinto*” etc. foram preservadas.

A **representação judicial da União** também continuou nas mãos do Ministério Público Federal (cf. **Lei n. 1.341/51** — *Lei Orgânica do Ministério Público da União*, que veio a ser substituída pela LC n. 75/93), sendo que o art. 95, § 2.º, da EC n. 1/69 expressamente disciplinou que, nas comarcas do interior, a **União** poderia ser **representada** pelo **Ministério Público estadual**.

A EC n. 1/69, em seu art. 94, estabeleceu, ainda, que **lei** organizaria o **MPU** junto aos juízes e tribunais federais, bem como o **MP Estadual** seria organizado em carreira por **lei estadual**.

Mantendo essa regra de organização do MP Estadual por **lei estadual**, a **EC n. 7/77 inovou** ao prescrever que **lei complementar federal**, de iniciativa do Presidente da República, estabeleceria **normas gerais** a serem adotadas na organização do **Ministério Público Estadual**.

A título de informação, referida regulamentação se deu pela **LC n. 40, de 14.12.81**, lembrando que, com a promulgação do texto de 1988, o entendimento a que se chegou foi no sentido de **não mais se exigir** para referida regulamentação a modalidade de **lei complementar**, em razão da **falta de previsão** no art. 61, § 1.º, II, “d”.

Isso porque, do ponto de vista *material*, e já estudamos esse assunto no *capítulo sobre o processo legislativo* (cf. *item 9.14.2.2.1*), toda vez que o constituinte quisesse que a matéria seja regulamentada por lei complementar, deverá fazer **pedido expresse**. Não havendo declarada previsão e não sendo hipótese das outras espécies normativas, pelo campo residual, chegou-se à conclusão de que a matéria deve ser regulamentada por *lei ordinária*.

Nesse sentido, a **Lei n. 8.625, de 12.02.93**, instituiu a *Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP)* e dispôs sobre **normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados**, além de dar outras providências.³

■ 12.2.1.9. Constituição de 1988

O texto de 1988 consagrou a evolução do Ministério Público, separando-o

dos Poderes e o alocando no capítulo que trata das *funções essenciais à Justiça* (*Seção I do Capítulo IV do Título IV*).

Em verdadeira **consagração**, o MP foi elevado à posição de **instituição permanente** e **desatrelado**, de vez, **da representação judicial da União**, tanto é que, de maneira categórica e enérgica, o art. 129, IX, expressamente **vedou a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas**, ficando essa atribuição nas mãos da advocacia pública.

A CF/88, em seu art. 131, *caput*, fez a previsão expressa da **Advocacia-Geral da União**, instituição que, **diretamente** ou por meio de **órgão vinculado**, passou a **representar a União, judicial e extrajudicialmente**, cabendo-lhe, nos termos da **lei complementar** que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de **consultoria e assessoramento jurídico** do **Poder Executivo**.

Cabe observar, apesar das novas regras, que, por força do **art. 29, caput, do ADCT**, a **representação judicial da União** manteve-se **afeta ao Ministério Público Federal** até o advento da **LC n. 73/93**.

■ 12.2.2. Definição e investidura (“quarentena de entrada”)

De acordo com o art. 127, *caput*, da CF/88, o **Ministério Público** é instituição **permanente, essencial à função jurisdicional do Estado**, incumbindo-lhe a **defesa da ordem jurídica, do regime democrático** e dos **interesses sociais e individuais indisponíveis**.⁴

Regulamentando a CF/88, foram editados os seguintes diplomas legais:

■ **Lei n. 8.625, de 12.02.1993**: Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispondo sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados (iniciativa reservada ao Presidente da República, na forma da parte final do art. 61, § 1.º, II, “d”, CF/88);

■ **Lei Complementar n. 75, de 20.05.1993**: Lei Orgânica do Ministério Público da União (de caráter federal e não nacional, como a Lei Orgânica **Nacional** do Ministério Público), dispondo sobre a organização, atribuição

e estatuto do Ministério Público da União (Ministério Público Federal — arts. 37-82; Ministério Público Militar — arts. 116-148; Ministério Público do Trabalho — arts. 83-115 e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios — arts. 149-181, todos independentes entre si);⁵

■ **Leis complementares estaduais:** cada Estado elabora a sua. Assim, de acordo com o edital do concurso público estadual, o candidato atento deverá estudar a **respectiva lei orgânica**.

Significando importante garantia constitucional, as funções do Ministério Público só poderão ser exercidas por **integrantes da carreira**, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

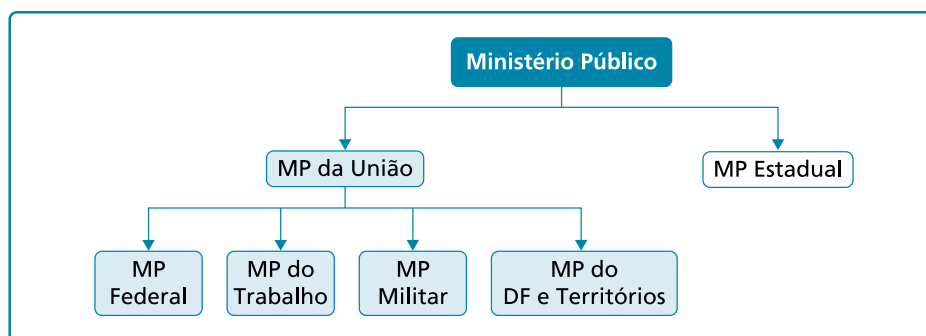
Nos termos do art. 129, § 3.º, da CF/88, o **ingresso** na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, **3 anos de atividade jurídica** e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.

De maneira bastante acertada, o **Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)** editou a **Res. n. 87/2012-CNMP** estabelecendo que a comprovação do período de 3 anos de atividade jurídica deverá ser documentada e formalizada para o ato da **posse** do candidato aprovado em todas as fases do concurso público, e não com o ato de mera inscrição definitiva no respectivo certame.

Isso porque a expressão “**ingresso**” deve ser interpretada como sinônimo de **investidura**, que somente se efetivará com a **posse** no **cargo**.

■ 12.2.3. Organização do Ministério Público na CF/88 — art. 128, I e II, e MP Eleitoral

■ 12.2.3.1. Organização do Ministério Público da União e Estadual



Como se vê, o art. 128, I, tratou do **MP da União**, enquanto o art. 128, II, do **MP dos Estados**.

No mesmo sentido em que no organograma do Judiciário se fala em “justiça comum” e “justiça especializada”, também aqui se observa um Ministério Público que atua na “justiça comum”, no caso, tanto a Federal (**MPF** — art. 109, nas matérias de competência da Justiça Federal) como a Estadual (**MP Estadual**), bem como aquele que atua perante os ramos especializados da Justiça Federal, quais sejam, o **MPT**, o **MPM** e também na **Justiça Eleitoral**, com as suas particularidades, como se verá no *item* seguinte.

Cumprir notar que, apesar de no âmbito **federal** existir uma carreira própria do Ministério Público para atuação perante a **Justiça Militar da União**, qual seja, o **MPM** (art. 128, I, “c”), no âmbito **estadual**, seja em primeiro grau (**Auditorias Militares**, que correspondem às Varas na Justiça Comum), seja no TJ ou no TJM onde houver (SP, MG e RS — art. 125, § 3.º, da CF/88), a atuação dar-se-á por membro do **MP Estadual**, **não havendo uma carreira própria e específica** de *Ministério Público Militar Estadual*. Trata-se de *Promotoria de Justiça especializada* com atuação perante a Auditoria Militar.

Por sua vez, não obstante haja ampla aproximação entre Estados e o DF, a previsão do **MP do DF e dos Territórios** como ramo do MP da União se justifica já que, segundo o art. 21, XIII, ele será organizado e mantido pela **União**.

■ 12.2.3.2. **MP Eleitoral**

O **MP Eleitoral** não tem estrutura própria, e a sua formação, como se

percebe pelo quadro abaixo, é **mista**, sendo composto de membros do Ministério Público Federal (**MPF**) e do Ministério Público Estadual (**MPE**).

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL		
Órgãos do MPE	Grau de jurisdição	Matéria de competência originária
■ Procurador-Geral Eleitoral (PGR) ■ Vice-Procurador-Geral Eleitoral (integram o MPF)	■ TSE	■ Eleição presidencial
■ Procuradores Regionais Eleitorais (integram o MPF)	■ TREs ■ Juízes auxiliares 6	■ Eleições federais, estaduais e distritais
■ Promotores Eleitorais (integram o MP Estadual)	■ Juízes eleitorais ■ Juntas eleitorais 7	■ Eleições municipais

Observa-se que não há na Constituição a previsão da carreira específica do *Ministério Público Eleitoral*. Aliás, o texto, além de ser silente no art. 128, não tratou do assunto em nenhuma passagem da Carta.

Diante dessa lacuna e da importância da **função eleitoral do MP**, vozes na doutrina sustentam, com razão, a criação, por emenda, de uma *carreira própria do MP Eleitoral* que, no caso, pertenceria ao ramo do **MPU**, modificando, portanto, o art. 128.

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, com precisão, observa que “... a

importância que as questões eleitorais têm ganhado na sociedade brasileira serve de contínua recomendação para que essa **nova instituição** seja criada. Seria um **novo ramo** do Ministério Público da União, tendo em vista o **caráter federal** de que se reveste toda a Justiça e o Direito Eleitoral”.⁸

Portanto, podemos falar que a **função eleitoral**, desempenhada pelo Ministério Público, tem **natureza federal** e é o que se depreende do art. 78 da LC n. 75/93 ao dispor que as **funções eleitorais do Ministério Público Federal** perante os **Juízes** e **Juntas Eleitorais** serão exercidas pelo **Promotor Eleitoral**, que é integrante do **MP Estadual**.

Diante desse regramento, conclui Gonçalves que, “quando atuam como órgãos eleitorais, os **Promotores de Justiça** o fazem como **Ministério Público Federal**, estando sujeitos à legislação que rege o *parquet* federal”.⁹

Nesse sentido, o art. 72 da LC n. 75/93 estabeleceu ser competência do **Ministério Público Federal** o exercício, no que couber, perante a Justiça Eleitoral, das funções do Ministério Público, atuando em **todas as fases e instâncias do processo eleitoral**.

Ou seja, também em primeira instância a lei fixou que a atribuição é do MPF, sendo que, por expressa previsão normativa (art. 78), essa função é exercida pelo MP Estadual.

O art. 37, I, da LC n. 75/93, na mesma linha, prescreve que o *Ministério Público Federal* exercerá as suas funções nas causas de competência dos **Tribunais** e **Juízes Eleitorais**.

■ 12.2.4. Chefe do Ministério Público

■ 12.2.4.1. Procurador-Geral da República

O **Ministério Público da União** tem por chefe o **Procurador-Geral da República**, nomeado pelo Presidente da República dentre **integrantes da carreira**, maiores de **35 anos**, após a aprovação de seu nome pela **maioria absoluta** dos membros do Senado Federal, para mandato de **2 anos**,¹⁰

permitida **mais de uma recondução**, sem qualquer limite (art. 128, § 1.º). No entanto, para cada nova recondução o procedimento e os requisitos deverão ser observados, já que a recondução é uma nova nomeação.

O Procurador-Geral da República poderá ser **destituído** pelo próprio Presidente da República, dependendo, contudo, de prévia autorização da **maioria absoluta** do Senado Federal (art. 128, § 2.º — novidade, já que, anteriormente, a escolha e a exoneração davam-se *ad nutum* pelo Presidente da República). A regra aqui é diferente da dos Estados e do DF e Territórios, pois o Chefe do MPU (PGR) poderá ser destituído pelo próprio **Executivo**, após prévia autorização do Legislativo. Os Chefes dos MPs dos Estados e do DF e Territórios (Procurador-Geral de Justiça) são destituídos pelo próprio **Legislativo** na forma da lei complementar respectiva (art. 128, § 4.º), e **não** pelo Executivo.

Em relação ao **subsídio do Procurador-Geral da República** de que tratam os arts. 39, § 4.º; 127, § 2.º; e 128, § 5.º, I, “c”, da CF/88, a **Lei n. 11.144/2005**, nos mesmos termos e limites da Lei n. 11.143/2005 (que fixou os subsídios dos Ministros do STF — teto do funcionalismo), estabeleceu que o subsídio mensal do Procurador-Geral da República seria de R\$ 21.500,00 a partir de 1.º.01.2005 e, a partir de 1.º.01.2006, de R\$ 24.500,00, correndo as despesas resultantes da aplicação da lei à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União.

Tendo em vista o aumento de 5% fixado pela Lei n. 12.042, de 08.10.2009, a partir de 1.º.09.2009, o subsídio mensal do PGR passou a ser de **R\$ 25.725,00**, prevendo-se, na referida lei, um novo aumento de 3,88% a partir de 1.º.02.2010, quando atingiu o valor de **R\$ 26.723,13**.

Finalmente, as **Leis ns. 12.770/2012** e **13.092/2015** estabeleceram novos valores para o subsídio do Procurador-Geral da República. Vejamos:

- **R\$ 28.059,29**: a partir de 1.º.01.2013;
- **R\$ 29.462,25**: a partir de 1.º.01.2014; e
- **R\$ 33.763,00**: a partir de 1.º.01.2015.

■ 12.2.4.2. *Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios*

Os **Ministérios Públicos dos Estados** e do **Distrito Federal e Territórios** formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seus **Procuradores-Gerais**, que serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo (Governador para os Estados e *Presidente da República* para o chefe do MP do DF e Territórios) para mandato de 2 anos, permitida **uma única recondução**. O Chefe do Ministério Público, nesta hipótese, designa-se **Procurador-Geral de Justiça — PGJ** (art. 128, § 3.º).

Em relação ao **Procurador-Geral de Justiça dos Estados**, o art. 9.º da Lei n. 8.625/93 determina que a lista tríplice será formada pelo próprio MP, na forma da lei respectiva de cada Estado, mediante voto plurinominal de todos os integrantes da carreira. [11](#) A destituição do PGJ dos Estados será implementada pela **Assembleia Legislativa local**, por deliberação de sua **maioria absoluta**, na forma da lei orgânica do respectivo Ministério Público. [12](#)

Já em relação ao **Procurador-Geral de Justiça do DF e Territórios**, o art. 2.º, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93 dispõe que a organização, atribuições e estatuto do MP do DF e Territórios serão objeto da Lei Orgânica do MP da União, qual seja, da LC n. 75/93.

Essa vinculação à União é natural, visto que, a teor dos arts. 21, XIII, e 22, XVII, da CF/88, compete à União organizar e manter o MP do DF e Territórios.

O art. 156, *caput*, da LC n. 75/93 estatui que o Procurador-Geral de Justiça do DF e Territórios será nomeado pelo **Presidente da República** (e não Governador do DF ou de Territórios) dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida **uma** recondução, precedida de nova lista tríplice.

Concorrerão à lista tríplice os membros do MP do Distrito Federal com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos 4 anos, condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo.

Em relação à destituição, o art. 128, § 4.º, da CF/88 estabelece que o PGJ do

DF e Territórios será destituído por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, **na forma da lei complementar**. A LC é a de n. 75/93, que, em seu art. 156, § 2.º, dispõe: “o Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por deliberação da **maioria absoluta do Senado Federal**, mediante representação do Presidente da República”. **Cuidado**: não é pela Câmara Legislativa do DF, e sim, enfatize-se, pela maioria absoluta do SF!

Cabe alertar, contudo, que, para o grande mestre José Afonso da Silva, a destituição do PGJ do DF e Territórios “... depende de deliberação do Poder Legislativo que, como órgão da União, é o **Congresso Nacional**”, não aceitando somente uma das Casas, que, conforme apontado, é o Senado Federal.

Dessa forma, para as provas, é importante saber essa renomada opinião, mas, na medida em que o art. 128, § 4.º, da CF/88 estabelece que o procedimento de destituição implementar-se-á **nos termos da lei complementar**, que, no caso, é a de n. 75/93, orientamos adotar a regra de seu art. 156, § 2.º, qual seja, como visto, o PGJ do DF e Territórios será destituído pela **maioria absoluta do Senado Federal**.

Por fim, uma dúvida pode surgir. E em caso de vacância do cargo, o novo Procurador-Geral assume pelo tempo que resta para completar os 2 anos (mandato-tampão) ou cumpre um novo “mandato” de 2 anos completos?

O novo Procurador-Geral deve cumprir os 2 anos, vale dizer, um **novo período completo de 2 anos**, já que, segundo José Afonso da Silva, não se trata de mandato, mas sim de **investidura a tempo certo**. E o STF já decidiu que: “por ofensa ao § 3.º do art. 128 da CF — que fixa em dois anos o mandato dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal —, o Tribunal, julgando procedente a ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República, declarou, na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia (LC estadual n. 11/96), a inconstitucionalidade das disposições que previam, no caso de vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça, a eleição e nomeação de novo Procurador-Geral para que completasse o período restante do mandato de seu antecessor. ADI 1.783-BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 11.10.2001 (ADI 1.783)” (*Inf. 245/STF*, de 08 a

12.10.2001).

Outra questão já decidida pelo STF está relacionada à impossibilidade de se exigir prévia aprovação da indicação do nome do **PGJ** pela maioria absoluta do Legislativo local, sob pena de ferir o art. 128, § 3.º, da CF/88, que traz como única exigência a lista tríplice, na forma da lei, devendo o Chefe do Executivo nomear um dentre os integrantes da lista (cf. ADI 1.228-MC/AP, *DJU* de 02.06.1995; ADI 1.506-SE, *DJU* de 12.11.1999; ADI 1.962-RO, Rel. Min. Ilmar Galvão, 08.11.2001, e, mais recentemente, **ADI 3.727**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 12.05.2010, Plenário, *DJE* de 11.06.2010).

■ 12.2.4.3. *Procurador-Geral do Trabalho*

Nos termos dos arts. 87 e 88 da LC n. 75/93 (*que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União*), o **Procurador-Geral do Trabalho** será o Chefe do Ministério Público do Trabalho, nomeado pelo **PGR**, dentre membros da Instituição, com **mais de 35 anos de idade** e **de 5 anos na carreira**, integrante de **lista tríplice** escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo **Colégio de Procuradores**,¹³ para um mandato de **2 anos**, permitida **uma recondução**, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira.

A sua **exoneração**, antes do término do mandato, será proposta ao **PGR** pelo **Conselho Superior**,¹⁴ mediante deliberação obtida com base em **voto secreto** de **2/3** de seus integrantes.

■ 12.2.4.4. *Procurador-Geral da Justiça Militar*

Já os arts. 120 e 121 da LC. n. 75/93 prescrevem que o **Procurador-Geral da Justiça Militar** será o Chefe do Ministério Público Militar, nomeado pelo **PGR**, dentre integrantes da Instituição, também com **mais de 35 anos de idade**

e de 5 anos na carreira, escolhidos em **lista tríplice** mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo **Colégio de Procuradores**,¹⁵ para um mandato de **2 anos**, permitida **uma recondução**, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira.

A sua **exoneração** antes do término do mandato será proposta ao **PGR** pelo **Conselho Superior**,¹⁶ mediante deliberação obtida com base em **voto secreto** de **2/3** de seus integrantes.

■ 12.2.4.5. *Procurador-Geral Eleitoral*

Conforme vimos, o art. 73 da LC n. 75/93 consigna que o **Procurador-Geral Eleitoral** é o próprio **PGR** que exerce as funções do Ministério Público nas causas de competência do **TSE**.

Por sua vez, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o provimento definitivo.

Ainda, além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, **por necessidade de serviço**, membros do *Ministério Público Federal* para **oficiarem**, com sua aprovação, perante o **TSE**.

■ 12.2.4.6. *Procurador Regional Eleitoral*

Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral (que é o PGR, reforçamos) designar o **Procurador Regional Eleitoral** em cada Estado e no Distrito Federal, juntamente com o seu **substituto**, dentre os *Procuradores Regionais da República* no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os Procuradores da República vitalícios, para **mandato de 2 anos**, podendo ser **reconduzido uma vez**.

Na prática, buscando dar maior legitimidade — apesar da inexistência de previsão normativa —, vêm sendo realizadas eleições no âmbito do MPF para a

escolha dos 2 nomes (candidatos a *Procurador Regional Eleitoral* e o seu *substituto*) e, normalmente, sem ter essa obrigação, o PGR vem escolhendo os integrantes da *chapa* mais votada.

De acordo com o art. 76, § 2.º, da LC n. 75/93, o *Procurador Regional Eleitoral* poderá ser **destituído**, antes do término do mandato, por **iniciativa** do **Procurador-Geral Eleitoral**, anuindo a **maioria absoluta** do **Conselho Superior do Ministério Público Federal**. [17](#)

Compete ao **Procurador Regional Eleitoral** exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do **Tribunal Regional Eleitoral** respectivo, além de **dirigir**, no **Estado**, as **atividades do setor**.

Nesse sentido, a **Res. n. 30/2008** do *Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)*, traçando parâmetros para a indicação e a designação de membros do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1.º grau, estabeleceu competir tal atribuição ao **Procurador Regional Eleitoral**, com base em **indicação** do **Chefe do Ministério Público local**, qual seja, com base na indicação do *Procurador-Geral de Justiça (PGJ)*.

Finalmente, cumpre observar que o *Procurador-Geral Eleitoral* poderá designar, por **necessidade de serviço**, outros membros do **MPF** para officiar, sob a **coordenação do Procurador Regional**, perante os **TREs**.

■ 12.2.4.7. *Novas perspectivas em relação à nomeação do PGR*

A “**PEC Paralela do Judiciário**” (PEC n. 358/2005, que voltou à CD, já aprovada, como 29-A, no SF), modificando o art. 128, § 1.º, explicita que o **PGR** deva ser oriundo do **MPF** (tendo em vista as atribuições especializadas dos MPs do Trabalho e Militar e a atuação limitada a uma unidade da Federação do MP do DF e Territórios) e permite, diferentemente da regra atual, apenas **uma recondução**.

Essa informação é importante para as provas (oral e escrita — para demonstrar conhecimento), **mas ainda depende de aprovação em 2 turnos da CD**.

■ 12.2.5. Princípios institucionais

■ 12.2.5.1. Regras gerais

O art. 127, § 1.º, da CF/88 prevê como princípios institucionais do Ministério Público a *unidade*, a *indivisibilidade* e a *independência funcional*.

■ **unidade:** sob a égide de um só Chefe, o Ministério Público deve ser visto como uma instituição única, sendo a divisão existente meramente **funcional**. Importante notar, porém, que a unidade se encontra dentro de cada órgão, não se falando em unidade entre o Ministério Público da União (qualquer deles) e o dos Estados, nem entre os ramos daquele;

■ **indivisibilidade:** corolário do princípio da unidade, em verdadeira relação de logicidade, é possível que um membro do Ministério Público substitua outro, dentro da mesma função, sem que, com isso, exista alguma implicação prática. Isso porque quem exerce os atos, em essência, é a instituição “Ministério Público”, e não a pessoa do Promotor de Justiça ou Procurador;

■ **independência funcional:** trata-se de autonomia de convicção, na medida em que os membros do Ministério Público não se submetem a nenhum poder hierárquico no exercício de seu mister, podendo agir, no processo, da maneira que melhor entenderem. A hierarquia existente restringe-se às questões de caráter administrativo, materializada pelo Chefe da Instituição, mas nunca, como dito, de caráter funcional. Tanto é que o art. 85, II, da CF/88 considera **crime de responsabilidade** qualquer ato do Presidente da República que atentar contra o livre-exercício do Ministério Público.

■ 12.2.5.2. *Legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual para o ajuizamento de reclamação no STF, sem que se exija a ratificação da inicial pelo PGR*

A análise sobre a legitimidade autônoma ou não do **MP Estadual** para o ajuizamento de **reclamação** perante o STF (art. 102, I, “I”, da CF/88) foi

discutida nos autos da **Rcl 7.358**, na qual se analisava o suposto descumprimento da *súmula vinculante 9*, pelo TJ/SP, que restabeleceu o direito de remição do executado, apesar de cometimento de falta grave. [18](#)

A discussão surgiu a partir do voto da Rel. Min. Ellen Gracie que, em razão do art. 46 da LC n. 75/93, entendeu que o PGR teria a atribuição exclusiva para atuação perante o STF.

O citado art. 46 determina ser incumbência do *Procurador-Geral da República* exercer as funções do Ministério Público junto ao STF, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência.

Contudo, o Min. Marco Aurélio, em divergência, sustentou que, como o MP Estadual havia atuado na 1.^a e na 2.^a instâncias, não teria sentido retirar a atribuição para o ajuizamento de *reclamação* do *parquet* estadual.

Ao final, referida *questão de ordem* foi resolvida por 6 x 4, concluindo o STF, nos termos da divergência aberta, pelo reconhecimento da legitimidade **autônoma** do MP Estadual para a propositura de **reclamação** perante o STF, sem a necessidade de requerimento junto ao PGR, que, no caso, atuaria não como parte, mas como *custos legis*.

Explica o Min. Celso de Mello: “(...) o **Ministério Público estadual**, quando atua no desempenho de suas prerrogativas institucionais e no âmbito de processos cuja natureza justifique a sua formal participação (quer como órgão agente, quer como órgão interveniente), dispõe, ele próprio, de **legitimidade para ajuizar reclamação**, em sede **originária**, perante o **STF**. Não tem sentido, por implicar ofensa manifesta à **autonomia institucional do Ministério Público dos Estados-membros**, exigir-se que a sua atuação processual se faça por intermédio do Senhor Procurador-Geral da República, que não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do *Parquet* estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (CF, art. 128, § 1.º), a chefia do **MPU**. É importante assinalar, porque juridicamente relevante, que o postulado da **unidade institucional** (que também se estende ao Ministério Público dos Estados-membros) reveste-se de natureza constitucional (CF, art. 127, § 1.º), a significar que o Ministério Público estadual não é

representado — muito menos chefiado — pelo Senhor Procurador-Geral da República, eis que é plena a autonomia do *Parquet* local em face do eminente chefe do MPU. Mostra-se fundamental insistir na asserção de que **o Ministério Público dos Estados-membros não está vinculado nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, a chefia do MPU**, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, em sede de reclamação, perante o STF” (**Rcl 7.245**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 02.08.2010, *DJE* de 05.08.2010). [19](#)

Outro argumento trazido pelo Min. Cezar Peluso foi a constatação de que o art. 46 da LC n. 75/93 se encontra dentro de seção que trata apenas do MPF, não podendo, assim, exigir a aplicação da referida regra quando o MP Estadual for parte.

Finalmente, na medida em que o **PGR** é o Chefe do **MPU**, que, na forma do art. 128, I, compreende o *MPF*, o *MPT*, o *MPM* e o *MP do DF e Territórios*, esse novo entendimento, que assegura o ajuizamento autônomo de reclamação perante o STF pelo MP Estadual, não vem sendo aceito pela Suprema Corte em relação aos ramos do MPU, havendo decisões firmes e expressas em relação ao MPT:

“EMENTA: **Ausência de legitimidade do MPT para atuar perante a Suprema Corte. Atribuição privativa do Procurador-Geral da República.** (...) Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao STF, nos termos do art. 46 da LC 75/93. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. O exercício das **atribuições do MPT** se **circunscreve aos órgãos da Justiça do Trabalho**, consoante se infere dos arts. 83, 90, 107 e 110 da LC 75/93. Agravo regimental interposto pelo MPT contra decisão proferida em reclamação ajuizada nesta Casa. Processo que não está sujeito à competência da Justiça do Trabalho, mas sim do próprio STF, motivo por que **não pode o MPT nele atuar, sob pena de usurpação de atribuição conferida privativamente ao Procurador-Geral da República**” (**Rcl 4.453-MC-AgRagR** e **Rcl 4.801-MC-AgR**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.03.2009, Plenário, *DJE* de 26.03.2009). [20](#)

■ 12.2.6. Princípio do promotor natural

Além de ser julgado por órgão independente e pré-constituído, o acusado também tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, **vedando-se**, por consequência, a **designação arbitrária**, inclusive, de **promotores *ad hoc*** ou **por encomenda** (art. 5.º, LIII, e art. 129, I, c/c o art. 129, § 2.º). [21](#)

Na doutrina o tema foi bastante debatido, chegando alguns autores a defendê-lo antes mesmo da atual Constituição, destacando-se, pioneiramente, Hugo Nigro Mazzilli, Jaques de Camargo Penteado, Clóvis A. Vidal de Uzeda e Paulo Cesar Pinheiro Carneiro.

A CF/1988 assegura que ninguém será **processado** nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5.º, LIII).

Depois de muito debate, a Suprema Corte aceitou a ideia de *promotor natural*, recomendando-se a discussão no *leading case*, que foi o **HC 67.759**.

Em referido julgamento, o Min. Celso de Mello estabeleceu que “o postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da **vedação de designações casuísticas** efetuadas pela **Chefia da Instituição**, a figura do **acusador de exceção**. Esse princípio consagra uma **garantia de ordem jurídica**, destinada tanto a **proteger o membro do Ministério Público**, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar **a própria coletividade**, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e predeterminados, estabelecidos em lei. A **matriz constitucional** desse princípio assenta-se nas cláusulas da **independência funcional** e da **inamovibilidade** dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável” (**HC 67.759**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.08.92, Plenário, *DJ* de 1.º.07.93).

Em outro julgado, o Min. Celso de Mello, de maneira interessante, asseverou que “a consagração constitucional do princípio do Promotor Natural significou o banimento de ‘manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição’ (HC 71.429/SC), em ordem a fazer suprimir, de vez, a figura esdrúxula do ‘acusador de exceção’ (HC 67.759/RJ). O legislador constituinte, ao proceder ao **fortalecimento institucional do Ministério Público**, buscou alcançar duplo objetivo: (a) instituir, em favor de qualquer pessoa, a garantia de **não sofrer arbitrária persecução penal instaurada por membro do Ministério Público designado ‘ad hoc’** e (b) tornar mais intensas as prerrogativas de **independência funcional** e de **inamovibilidade** dos integrantes do ‘Parquet’. A garantia da independência funcional, viabilizada, dentre outras, pela prerrogativa da inamovibilidade, reveste-se de caráter tutelar. É de ordem institucional (CF, art. 127, § 1.º) e, nesse plano, acentua a posição autônoma do Ministério Público em face dos Poderes da República, com os quais não mantém vínculo qualquer de subordinação hierárquico-administrativa” (HC 102.147, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 16.12.2010, DJE de 03.02.2011).

Buscando sistematizar, a doutrina avança e, conforme ensina Carneiro, a garantia do **promotor natural** passa, necessariamente, por **quatro exigências básicas**:

- “pessoa investida no cargo de promotor;
- existência de órgão de execução;
- lotação por titularidade e inamovibilidade do promotor do órgão de execução, ressalvadas as hipóteses legais de substituição e remoção;
- definição em lei das atribuições do cargo”.[22](#)

Nelson Nery Junior, por seu turno, partindo da ideia de **promotor natural**, ao tratar das **equipes especializadas de investigação** do Ministério Público observa que “... criadas com o objetivo de melhor distribuir a promoção da justiça pelo *Parquet*, são salutares e devem ser mantidas. Entretanto, seus componentes deverão ser Promotores de Justiça com cargo fixo e com

atribuições designadas na lei, de sorte a respeitar-se o princípio do promotor natural e a garantia da inamovibilidade de que goza o membro do Ministério Público. Entender-se o contrário, retirando do órgão do *Parquet* atribuição para funcionar na equipe especializada, seria o mesmo que negar-lhe a inamovibilidade, garantida pela Constituição Federal. Os promotores de justiça de equipes especializadas não podem ser designados e removidos ao alvitre do Procurador-Geral de Justiça”.[23](#)

Veja, finalmente, lembrando que o tema deverá ser aprofundado nos livros de *direito penal e processual penal*, interessante aplicação do **princípio do promotor natural na jurisprudência do STF**:

A) Pedido de arquivamento dos autos do inquérito policial por um promotor de justiça e oferta da denúncia por outro

“EMENTA: (...) Crime de homicídio qualificado. Alegação de violação ao princípio do promotor natural e de ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia. Inexistência de constrangimento ilegal. Nenhuma afronta ao princípio do promotor natural há no **pedido de arquivamento dos autos do inquérito policial** por um promotor de justiça e na **oferta da denúncia por outro**, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, após o Juízo local ter considerado improcedente o pedido de arquivamento. A **alegação de falta de justa causa para o oferecimento da primeira denúncia foi repelida pelo Tribunal de Justiça estadual**, sendo acatada tão somente a tese de sua inépcia. Não se pode trancar a segunda denúncia, quando descritos, na ação penal, comportamentos típicos, ou seja, quando factíveis e manifestos os indícios de autoria e materialidade delitivas. (...)” (**HC 92.885**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.04.2008, *DJE* de 20.06.2008).

B) Ocorrência de opiniões colidentes manifestadas, em momentos sucessivos, por procuradores de justiça oficiantes no mesmo procedimento recursal

Em outro interessante julgado, o STF teve de enfrentar a seguinte situação: após interposição do recurso em sentido estrito, determinado procurador de justiça emitiu parecer pela **impronúncia**. Contudo, na sessão de julgamento, outro procurador de justiça se manifestou pelo **improvemento** do recurso e **confirmação da sentença de pronúncia**.

Diante disso, o STF admitiu a ocorrência de opiniões colidentes nos seguintes termos:

‘EMENTA: (...). Ocorrência de opiniões colidentes manifestadas, em momentos sucessivos, por procuradores de justiça oficiantes no mesmo procedimento recursal. Possibilidade jurídica dessa divergência opinativa. Pronunciamentos que se legitimam em face da **autonomia intelectual** que qualifica a atuação do membro do Ministério Público. Situação que não traduz ofensa ao postulado do promotor natural. Significado dos princípios constitucionais da **unidade** e da **indivisibilidade** do Ministério Público. ‘Habeas corpus’ parcialmente conhecido e, nessa parte, indeferido” (**HC 102.147**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 16.12.2010, *DJE* de 03.02.2011).

Deve-se deixar claro que o STF **não** passou a admitir a imotivada designação de promotores para atuarem, por encomenda, em casos específicos.

Na parte conclusiva de seu voto, o Min. Celso de Mello observa que o *princípio do Promotor Natural* **impede** o **arbitrário afastamento** do membro do Ministério Público do desempenho de suas atribuições nos procedimentos em que ordinariamente officie (ou em que deva officiar), exceto:

- “por relevante motivo de interesse público”;
- “por impedimento ou suspeição”;
- “por razões decorrentes de férias ou de licença”.

C) Designação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de outro promotor, com a concordância do promotor de justiça titular, para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele

O art. 10, IX, “F”, da Lei n. 8.625/93 (*LONMP*) estabelece ser competência do Procurador-Geral de Justiça designar membros do Ministério Público para assegurar a continuidade dos serviços, em caso de *vacância*, *afastamento temporário*, *ausência*, *impedimento* ou *suspeição* de titular de cargo, ou com **consentimento deste**.

Nesta última hipótese (“consentimento deste”), o art. 24 da *LONMP*

estabelece que o Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.

Diante do que foi amplamente exposto, entendemos conveniente que esse ato de designação seja **motivado** e dentro de **critérios de razoabilidade**, reprimindo substituições imotivadas ou por inaceitável e combatida encomenda.

Assim, parece correta a decisão do STF que validou a substituição de promotor titular, recém-promovido para determinada promotoria, em razão da **complexidade do feito**, com 14 volumes e diversos incidentes, e pelo fato de o indicado ter atuado como promotor de justiça originário/natural do caso quando exercia as suas atribuições na referida comarca do julgamento:

“EMENTA: (...). No caso, a designação prévia e motivada de um promotor para atuar na sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Izabel do Pará se deu em virtude de **justificada solicitação do promotor titular daquela localidade**, tudo em estrita observância aos artigos 10, inc. IX, alínea ‘f’, parte final, e 24, ambos da Lei n. 8.625/93. Ademais, o **promotor designado já havia atuado no feito quando do exercício de suas atribuições na Promotoria de Justiça da referida comarca**” (HC 103.038, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 11.10.2011, 2.^a Turma, DJE de 27.10.2011).

D) Propositura da ação penal nos casos previstos no art. 105, I, “a”, da CF/88, pelo Procurador-Geral da República perante o STJ. Possibilidade de delegação dessa competência a Subprocurador-Geral da República

Esse tema é muito interessante, e o STF chegou a analisar se seria possível atribuir ao PGR atuação perante outros tribunais, que não a Suprema Corte, por meio de ato infraconstitucional.

Ao que se percebe pela análise do caso concreto, a atribuição ao PGR para a propositura da ação penal perante o STJ nas hipóteses do art. 105, I, “a”, deu-se nos termos do art. 48, II, da LC n. 75/93, assim como a possibilidade de delegação dessa atribuição, nos termos do parágrafo único do referido art. 48.

Dessa forma, diante da previsão normativa, a legitimidade *ad processum* do

PGR para subscrever a denúncia em ação penal originária perante o STJ dar-se-á para processar e julgar, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos TJs dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos TCs dos Estados e do Distrito Federal, os dos TRFs, dos TREs e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou TCs dos Municípios e os do MPU que oficiem perante tribunais.

A constitucionalidade dessa atribuição foi discutida nos autos da **ADI 2.913**, ajuizada, à época, pelo então PGR Cláudio Fonteles.

Entre os argumentos expostos, estava a previsão de atuação do PGR somente perante o STF, conforme arts. 36, III; 102, I, “b”, e 102, VI, todos da CF/88.

Alegava-se que eventual fixação de atribuição para atuar perante outro tribunal que não o STF deveria dar-se por meio de explícita previsão constitucional ou por emenda à Constituição, conforme os termos da EC n. 45/2004 que estabeleceu a competência do PGR para o ajuizamento do **IDC** (*Incidente de Deslocamento de Competência*) perante o **STJ** (art. 109, § 5.º, da CF/88).

Contudo, em referido julgamento, o STF, por maioria, entendeu ser perfeitamente possível a ampliação de atribuições do PGR nos termos do **art. 128, § 5.º, da CF/88**, qual seja, por meio de **lei complementar**, notadamente, pela **LC n. 75/93**, que *dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União*.

Assim, de acordo com o art. 48, II, parágrafo único da referida LC n. 75/93, incumbe ao **Procurador-Geral da República** propor perante o **STJ** a ação penal, nos casos previstos no art. 105, I, “a”, da CF/88, podendo tal competência ser delegada a Subprocurador-Geral da República.

Confira a decisão do STF que, por 7 x 2, reconheceu a constitucionalidade do art. 48, II, parágrafo único, da LC n. 75/93:

“EMENTA: (...). AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES POR LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São constitucionais o inc. II e o parágrafo único do art. 48 da LC n. 75/93, que atribuem ao PGR a competência para propor, no STJ, a ação penal prevista no art. 105, I, ‘a’, da

Constituição da República, além de permitirem a delegação dessa competência a Subprocurador-Geral da República. 2. ADI julgada improcedente” (**ADI 2.913**, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, j. 20.05.2009, Plenário, *DJE* de 24.06.2011).

“EMENTA: Ação penal da competência originária do STJ: Ministério Público: legitimidade *ad processum* para subscrever a denúncia do Procurador-Geral da República: possibilidade de delegação a Subprocurador-Geral da República. LC 75/93 (*LOMPU*), arts. 48, II, parágrafo único: validade. Válida e vigente a disposição legal que atribui ao Procurador-Geral a propositura das ações penais da competência originária do STJ, não há como cogitar, em relação a elas, de distribuição, cujo pressuposto é a pluralidade de órgãos com idêntica competência material: nelas o Procurador-Geral é, por definição legal, o ‘promotor natural’ da causa” (**HC 84.630**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15.12.2005, 1.^a Turma, *DJ* de 25.08.2006. No mesmo sentido, cf.: HC 84.468 e HC 84.488, Rel. Min. Cezar Peluso, 1.^a Turma, STF, j. 07.02.2006).

■ 12.2.7. Garantias do Ministério Público

■ 12.2.7.1. Garantias institucionais

■ 12.2.7.1.1. Autonomia funcional

A **autonomia funcional**, inerente à Instituição como um todo e abrangendo todos os órgãos do Ministério Público, está prevista no art. 127, § 2.º, da CF/88, no sentido de que, ao cumprir os seus deveres institucionais, o membro do Ministério Público não se submeterá a nenhum outro “poder” (Legislativo, Executivo ou Judiciário), órgão, autoridade pública etc. Deve obediência, apenas, à Constituição, às leis e à sua própria consciência.

■ 12.2.7.1.2. Autonomia administrativa

A **autonomia administrativa** consiste na capacidade de direção de si próprio, autogestão, autoadministração, um governo de si. Assim, o Ministério Público poderá, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, enfim, sua organização e funcionamento (cf. art. 127, § 2.º).[24](#)

■ 12.2.7.1.3. *Autonomia financeira*

Pela garantia institucional da **autonomia financeira**, ao Ministério Público assegurou-se a capacidade de elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, podendo, - autonomamente, administrar os recursos que lhe forem destinados (cf. art. 127, § 3.º).

Assim como fixado para a Magistratura e já estudado (art. 99, §§ 3.º, 4.º e 5.º), a **EC n. 45/2004** regulamentou o procedimento de encaminhamento da proposta orçamentária do Ministério Público e solução em caso de inércia. Proibiu, outrossim, a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites fixados na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais (**art. 127, §§ 4.º, 5.º e 6.º**).

■ 12.2.7.2. *Garantias dos membros do Ministério Público*

■ 12.2.7.2.1. *Vitaliciedade*

Adquire-se a **vitaliciedade** após a transcorrência do **período probatório**, ou seja, 2 anos de efetivo exercício do cargo, tendo sido admitido na carreira mediante aprovação em concurso de provas e títulos (art. 128, § 5.º, I, “a”). A garantia da vitaliciedade assegura ao membro do Ministério Público a **perda** do

cargo somente por **sentença judicial transitada em julgado**.[25](#)

■ **12.2.7.2.2. Inamovibilidade**

Em razão da garantia da **inamovibilidade**, o membro do Ministério Público não poderá ser **removido** ou **promovido**, unilateralmente, sem a sua autorização ou solicitação. Excepcionalmente, contudo, por motivo de **interesse público**, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público (no caso, o **Conselho Superior do Ministério Público**[26](#)), por voto da **maioria absoluta** de seus membros, desde que lhe seja assegurada ampla defesa, poderá vir a ser removido do cargo ou função (art. 128, § 5.º, I, “b”, modificado pela EC n. 45/2004).

■ **12.2.7.2.3. Irredutibilidade de subsídios**

É assegurada ao membro do Ministério Público (art. 128, § 5.º, I, “c”, da CF/88) a garantia da **irredutibilidade de subsídio**, fixado na forma do art. 39, § 4.º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI; 150, II; 153, III; 153, § 2.º, I. Como vimos ao comentar a irredutibilidade dos magistrados, o subsídio dos membros do Ministério Público não poderá ser reduzido, lembrando que está assegurada a irredutibilidade nominal, não se garantindo a corrosão inflacionária.[27](#)

■ **12.2.7.3. Impedimentos imputados aos membros do Ministério Público (vedações)**

De acordo com os arts. 128, § 5.º, II, § 6.º; e 129, IX, os membros do Ministério Público não poderão:

- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- exercer a advocacia.[28](#)

Em relação ao exercício da advocacia devemos observar que essa proibição **não é absoluta**.

O art. 29, § 3.º, do ADCT estabeleceu que o membro do Ministério Público poderia **optar pelo regime anterior**, no que respeita às **garantias** e **vantagens**, desde que admitido **antes da promulgação da Constituição**, observando-se, quanto às **vedações**, a **situação jurídica na data desta**.

Resta investigar, então, como era o regime anterior, quando da promulgação do texto, em relação à referida vedação:

■ **Ministério Público Estadual:** por expressa previsão do art. 24, § 2.º, da LC n. 40/81, os membros do *MP Estadual* estavam expressamente **proibidos** de advogar;

■ **Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios:** o art. 60 da LC n. 40/81 determinava aplicar-se à organização do *Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios*, no que coubesse, as normas constantes na referida Lei. Assim, no caso, aplicando-se a vedação constante do art. 24, § 2.º, em relação aos membros do MP Estadual, pode-se concluir que os membros do *MP do DF e dos Territórios* também estavam proibidos de advogar;

■ **Ministério Público Federal, da Justiça do Trabalho e junto à Justiça Militar:** os dispositivos normativos que disciplinavam a carreira do **MPU** (Lei n. 1.341/51 — *Lei Orgânica do Ministério Público da União*, que veio a ser substituída pela LC n. 75/93 e Lei n. 6.788/80; Decreto n. 40.359/56 — *MPT* e Decreto n. 73.173/73 — *MPM*) não traziam essa expressa vedação, exceto na hipótese de contrariar os interesses da União ou da Fazenda Nacional.

Podemos afirmar, então, que a vedação não era em relação a todo o Ministério Público, mas apenas para o **MP Estadual** e para o **MP do DF e dos Territórios**.

Portanto, os membros do **MPU** junto à Justiça Comum (**MPF**), à Militar (**MPM**) e à do Trabalho (**MPT**), com a exceção dos integrantes do *MP do DF e*

dos Territórios, podiam advogar, já que não havia expressa vedação.

Cabe referir, conforme os *considerandos* da **Res. n. 16/2006 do CNMP**, “que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, em abril de 1987, que a proibição de advogar, nos termos da Lei Complementar n. 40/81 e Decreto-lei n. 2.627/85, aplicava-se, integralmente, aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inexistindo, no caso, violação de direito adquirido, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico (AgRg 117.625-3, Rel. Ministro Moreira Alves)”.

O tema, por sua vez, foi regulamentado pelo CNMP, nos termos da citada Res. n. 16/2006 (ao dar nova redação ao art. 1.º da Res. n. 8/2006): “somente poderão exercer a advocacia com respaldo no § 3.º do art. 29 do ADCT da Constituição de 1988, os membros do **Ministério Público da União** que integravam a carreira na data da sua promulgação e que, desde então, permanecem regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. O exercício da advocacia, para os membros do *Ministério Público do Distrito Federal e Territórios* está, incondicionalmente, vedado, desde a vigência do artigo 24, § 2.º, da Lei Complementar n. 40/81”, além, é claro, conforme visto, da proibição em relação aos membros do *Ministério Público Estadual*.

É de lembrar que, na dicção do art. 2.º da Res. n. 8/CNMP, além dos impedimentos e vedações previstos na legislação que regula o exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público, quando puderem advogar, estes não poderão fazê-lo nas causas em que, por força de lei ou em face do interesse público, esteja prevista a atuação do Ministério Público, por qualquer dos seus órgãos e ramos (Ministérios Públicos dos Estados e da União).

Finalmente — e o tema será aprofundado quando tratarmos da AGU —, no **regime jurídico anterior**, os **membros do MPF** exerciam, além de outras atribuições, a **representação judicial da União**.

Com o novo texto, os membros do MPF ficaram proibidos de representar a União, mas, por força do art. 29, *caput*, do ADCT, eles continuaram, temporariamente, a exercer a advocacia, representando judicialmente a União, até que fosse editada a **Lei Complementar n. 73/93**.

- participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
- exercer atividade político-partidária; sem qualquer exceção, nos termos da restrição trazida pela **EC n. 45/2004**, ao alterar a redação do art. 128, § 5.º, II, “e” (cf. Res. n. 5/2006 do CNMP);

A Res. TSE n. 22.095/2005 (*DJ* de 24.10.2005, p. 89, nos termos da Res. TSE n. 22.045/2005) previu ser imediata a aplicação da EC n. 45/2004 e sem ressalvas, abrangendo aqueles que adentraram nos quadros do Ministério Público tanto antes quanto depois da referida emenda à Constituição. Também o art. 13 da Res. TSE n. 22.156/2006 estabeleceu que os magistrados, os membros dos Tribunais de Contas e os do **Ministério Público** devem filiar-se a partido político e afastar-se **definitivamente** de suas funções até 6 meses antes das eleições.

Em sentido contrário, porém, destacamos julgado do **TSE (decisão monocrática** do Min. Cezar Peluso) que entendeu pela não aplicação da regra da EC n. 45/2004, que veda o exercício de atividade político-partidária aos membros do MP, por força do **art. 29, § 3.º, do ADCT**, àqueles que ingressaram na carreira antes da promulgação da CF/88.

Destacamos o caso particular do **RO 1.070**, requerido por *Fernando Capez* no TSE, que confirmou a sua candidatura pela coligação PSDB/PFL em eleição na qual obteve 95.101 votos no pleito de 2006 para o exercício do mandato de Deputado Estadual (SP). [29](#)

Contra referido acórdão, foi interposto, em 14.10.2008, pelo Ministério Público Eleitoral, o **RE 594.154**. Tendo em vista que o mandato de deputado estadual a que se referia a candidatura impugnada iniciou-se em 1.º.01.2007 e teve fim em 31.12.2010, o recurso perdeu seu objeto, sendo, portanto, julgado prejudicado (art. 21, IX, do *RISTF*). Fernando Capez foi reeleito para nova legislatura, com término previsto para 31.12.2014.

Ainda, é de mencionar o interessante caso da Promotora de Justiça licenciada Maria do Carmo, que, considerada inelegível, teve seu registro de candidatura

indeferido pela Justiça Eleitoral, pois, apesar de estar tentando a reeleição, encontraria vedação no art. 128, § 5.º, II.

Contudo, tendo participado das eleições municipais de 2008 para a Prefeitura de *Santarém* (PA), obteve 77.458 votos, que equivalem a 52,81% dos votos válidos.

O STF, por 6 x 4, deu provimento ao **RE 597.994** interposto e validou o registro de sua candidatura, estabelecendo, assim, um interessante precedente:

“Não há, efetivamente, direito adquirido do membro do Ministério Público a candidatar-se ao exercício de novo mandato político. O que socorre a recorrente é o **direito, atual** — não adquirido no passado, mas atual — **a concorrer a nova eleição e ser reeleita**, afirmado pelo artigo 14, § 5.º, da Constituição do Brasil. Não há contradição entre os preceitos contidos no § 5.º do artigo 14 e no artigo 128, § 5.º, II, ‘e’, da Constituição do Brasil. A interpretação do direito, e da Constituição, não se reduz a singelo exercício de leitura dos seus textos, compreendendo processo de contínua adaptação à realidade e seus conflitos. A ausência de regras de transição para disciplinar situações fáticas não abrangidas por emenda constitucional demanda a análise de cada caso concreto à luz do direito enquanto totalidade. A exceção é o caso que não cabe no âmbito de normalidade abrangido pela norma geral. Ela está no direito, ainda que não se encontre nos textos normativos de direito positivo. Ao Judiciário, sempre que necessário, incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Ao fazê-lo não se afasta do ordenamento” (RE 597.994, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, j. 04.06.2009, *DJE* de 28.08.2009).

■ receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

■ exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos **3 anos** do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (*quarentena*), nos termos do art. 128, § 6.º, introduzido pela EC n. 45/2004;

■ exercer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

■ 12.2.7.4. Abrangência das garantias e impedimentos

As garantias e vedações apresentadas não têm aplicação integral, na medida em que o art. 29, § 3.º, do ADCT prevê a possibilidade de opção pelo regime anterior, no tocante às **garantias** e **vantagens**, na hipótese de o membro do Ministério Público ter sido admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às **vedações**, a situação jurídica na data da aludida promulgação. [30](#)

Assim, ou o membro do Ministério Público escolhia submeter-se às novas regras traçadas pela CF/88 (por nós já apontadas as garantias e vedações), ou escolhia o regime jurídico anterior, em que existia a regra do *concurso público*, da *estabilidade* (podendo ser demitidos ou por sentença judiciária, ou em virtude de processo administrativo em que se lhes facultasse a ampla defesa) e da *inamovibilidade*, a não ser mediante representação do Procurador-Geral, com fundamento em conveniência do serviço (art. 138, § 1.º, da Constituição de 1967).

■ 12.2.8. Funções institucionais do Ministério Público

As funções institucionais do Ministério Público estão contempladas no art. 129 da CF/88. Trata-se de rol meramente **exemplificativo**, uma vez que seu inciso IX estabelece que compete, ainda, ao Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade. Assim, suas funções podem ser exemplificadas como segue:

- titularidade e monopólio da ação penal pública, na forma da lei, com a única exceção prevista no art. 5.º, LIX, que admite ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal (sem, contudo, observe-se, retirar a titularidade da ação penal pública do Ministério Público); [31](#)

- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.³² Lembrar que a legitimação acima referida para a ação civil pública não impede a dos outros legitimados, conforme se observa pelo art. 5.º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no art. 128;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções³³ que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Cabe ressaltar que referidas funções institucionais só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, **salvo autorização do Chefe da Instituição**.

Seguindo a regra adotada para a Magistratura, pela *Reforma do Judiciário*, o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, **exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica** e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação (cf. Resoluções ns. 14/2006,³⁴ 24/2007, 40/2009, 57/2010 e 87/2012 do CNMP, bem como análise no *item 11.4* deste estudo).

Outrossim, em nítida aproximação com a carreira da Magistratura, o art. 129, § 4.º, dispõe que, no que couber, aplica-se ao Ministério Público o disposto no art. 93 (tema já estudado no *item 11.4*).

Finalmente, na busca da celeridade processual (art. 5.º, LXXVIII), o art. 129, § 5.º, estabelece que a distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

■ 12.2.9. A teoria dos “poderes implícitos” e o poder de investigação criminal pelo MP

Conforme estudamos no *item 3.8* deste trabalho, segundo a teoria dos **poderes implícitos**, quando o texto constitucional outorga competência explícita a determinado órgão estatal, implicitamente, pode-se interpretar, dentro de um contexto de **razoabilidade** e **proporcionalidade**, que a esse mesmo órgão tenham sido dados os meios necessários para a efetiva e completa realização dos fins atribuídos.

A grande questão que se coloca, então, é se o **poder de investigação** seria exclusivo ou não da polícia.

Em importante julgado, a 2.^a Turma do STF, ao analisar a temática dos **poderes investigatórios do MP**, entendeu que a denúncia poderia ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo próprio *Parquet*, não havendo necessidade de prévio inquérito policial.

Nesse sentido, não se reconheceu violação ao art. 144, § 1.º, I e IV, que, segundo o STF, deve ser harmonizado com as funções atribuídas ao MP, nos termos do art. 129, I, VI, VIII, IX, da CF/88. A **atuação do MP**, dessa forma, **aperfeiçoaria a persecução penal** (RE 535.478, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.10.2008, *DJE* de 21.11.2008). [35](#)

O Min. Gilmar Mendes, por seu turno, em julgado mais recente em relação aos precedentes citados, **reafirmou** ser legítimo o poder de investigação pelo MP (art. 129, CF/88; art. 5.º, CPP; art. 8.º, LC n. 75/93), devendo, contudo, haver **vigilância** e **controle** (o que se verifica mesmo em relação à atividade exercida pela Polícia). No caso concreto, de maneira muito interessante, estabeleceu alguns **condicionamentos**: “a atuação do *Parquet* deve ser, necessariamente, **subsidiária**, ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou

recomendável, se efetivem pela própria polícia, em hipóteses específicas, quando, por exemplo, se verificarem situações de lesão ao patrimônio público, de excessos cometidos pelos próprios agentes e organismos policiais (v.g. tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão, corrupção), de intencional omissão da Polícia na apuração de determinados delitos ou se configurar o deliberado intuito da própria corporação policial de frustrar, em função da qualidade da vítima ou da condição do suspeito” (**RHC 97.926**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.09.2014, 2.^a T., *DJE* de 29.09.2014).

Quando prolatadas referidas decisões pela 2.^a Turma/STF, ainda não havia decisão final e **específica** pelo **Pleno** sobre essa importante questão dos poderes de investigação do MP de modo exclusivo, e não complementar a eventual prova produzida pela Polícia. Existem diversas ações diretas no STF aguardando o julgamento de mérito (cf., por exemplo, as ADIs 2.943, 3.309, 3.317, 3.318, 3.329, 3.337 e 3.806, ou, ainda, afetados ao Plenário, entre outros, o **RE 593.727.36**

Esse último foi julgado pelo **Pleno**, afirmando a seguinte tese: “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei n. 8.906/94, art. 7.º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Estado Democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (SV n. 14), praticados pelos membros dessa Instituição” (**RE 593.727**, j. 14.05.2015 — pendente de publicação).

Como o acórdão ainda não havia sido publicado no momento do fechamento desta edição, pedimos vênias para transcrever parte do **Inf. 785/STF**: “a legitimidade do poder investigatório do órgão seria extraída da Constituição, a partir de cláusula que outorgaria o monopólio da ação penal pública e o controle

externo sobre a atividade policial. O *parquet*, porém, não poderia presidir o inquérito policial, por ser função precípua da autoridade policial. Ademais, a função investigatória do Ministério Público não se converteria em atividade ordinária, mas **excepcional**, a legitimar a sua atuação em casos de abuso de autoridade, prática de delito por policiais, crimes contra a Administração Pública, inércia dos organismos policiais, ou procrastinação indevida no desempenho de investigação penal, situações que, exemplificativamente, justificariam a intervenção subsidiária do órgão ministerial. Haveria, no entanto, a necessidade de fiscalização da legalidade dos atos investigatórios, de estabelecimento de exigências de caráter procedimental e de se respeitar direitos e garantias que assistiriam a qualquer pessoa sob investigação — inclusive em matéria de preservação da integridade de prerrogativas profissionais dos advogados, tudo sob o controle e a fiscalização do Poder Judiciário”.

Em nosso entender, a posição fixada mostra-se bastante razoável, na medida em que não se pode inferir que haja exclusividade na investigação criminal da polícia. Quando o art. 144, § 1.º, IV, dispõe ser exclusividade da polícia federal exercer as funções de polícia judiciária da União, o texto objetivou afastar essa atividade de outros órgãos **policiais**.

A possibilidade de investigação pelo MP decorreria de sua atribuição de promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei (art. 129, I), assim como das atribuições estabelecidas nos incisos VI e VIII do art. 129, da CF/88, apresentando-se como atividade totalmente compatível com as suas finalidades institucionais. Resta aguardar como o Plenário do STF vai resolver essa importante questão!

Para efeito de aprofundamento, cf. a **Res. n. 13/CNMP, de 02.10.2006** (alterada pela Res. n. 111/2014), que regulamenta o art. 8.º da LC n. 75/93, e o art. 26 da Lei n. 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a **instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal**, além de dar outras providências. [37](#)

Todo esse entendimento não deve sofrer qualquer alteração mesmo com o advento da **Lei n. 12.830/2013**, que dispôs sobre a investigação criminal

conduzida pelo Delegado de Polícia.

■ 12.2.10. Conselho Nacional do Ministério Público

■ 12.2.10.1. Regras gerais e composição

O **art. 130-A**, introduzido pela **EC n. 45/2004** e regulamentado pela **Lei n. 11.372/2006**, prevê a criação do **Conselho Nacional do Ministério Público**, composto de **14 membros** nomeados pelo **Presidente da República**, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do **Senado Federal**, para um mandato de **2 anos**, admitida **uma recondução**, sendo:

- o Procurador-Geral da República, que o preside, parecendo razoável, assim como entendemos em relação ao Ministro Presidente do STF no tocante ao CNJ, que o PGR deve ser considerado **membro nato** do CNMP, não havendo sentido a sua sabatina pelo Senado Federal (aplicação analógica do art. 103-B, § 2.º, e discussão no *item 11.13.4*);
- quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;
- três membros do Ministério Público dos Estados;
- dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
- dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

Conforme indicado acima, a regulamentação do art. 130-A se deu pela **Lei n. 11.372/2006**.

■ 12.2.10.2. Escolha dos membros do Ministério Público da União

Apenas recordando, dispõe o art. 128, I, “a”-“d”, que o MPU se divide em *Ministério Público Federal (MPF)*, *Ministério Público do Trabalho (MPT)*, *Ministério Público Militar (MPM)* e *Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)*.

Nos termos do art. 1.º, *caput*, da Lei n. 11.372/2006, os membros do CNMP oriundos do Ministério Público da União (MPU) serão escolhidos pelo Procurador-Geral de **cada um dos ramos**, a partir de lista tríplice composta de membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva Carreira.

Essas listas tríplices serão elaboradas pelos respectivos **Colégios de Procuradores** do MPF, do MPT e do MPM, e pelo **Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça** do MPDFT.

O nome escolhido pelo Procurador-Geral de cada um dos ramos será encaminhado ao Procurador-Geral da República, que o submeterá à aprovação do **Senado Federal** (*sabatina*), pela **maioria absoluta** e para um **mandato de 2 anos**, admitida **uma recondução**.

■ 12.2.10.3. Escolha dos 3 membros do Ministério Público dos Estados

De acordo com o art. 2.º da Lei n. 11.372/2006, os membros do CNMP oriundos dos **Ministérios Públicos dos Estados** serão indicados pelos respectivos **Procuradores-Gerais de Justiça**, a partir de lista tríplice elaborada pelos integrantes da carreira de cada instituição, composta de membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira.

Os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, em **reunião conjunta** especialmente convocada e realizada para esse fim, formarão lista com os 3 nomes indicados para as vagas destinadas a membros do Ministério Público dos Estados, a ser submetida à aprovação do Senado Federal, para, também,

sabatina pela **maioria absoluta** de seus membros, para **mandato de 2 anos**, admitida **uma recondução**.

■ **12.2.10.4. A sabatina no Senado Federal e a falta de critérios para a indicação dos demais membros do Conselho que não os oriundos da carreira do Ministério Público**

Os nomes indicados, na conformidade do quadro a seguir, deverão, com exceção do PGR (em nossa interpretação, membro nato), passar por uma **sabatina** no **Senado Federal** e, se aprovados pela **maioria absoluta** de seus membros, serão **nomeados pelo Presidente da República** (art. 84, XIV e XXVII, c/c o art. 130-A, *caput*).

O procedimento da sabatina está regulamentado pela **Res. n. 7/2005-SF**, que define as normas para a apreciação das indicações.

De acordo com o seu art. 2.º, todos os indicados serão sabatinados pela *Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania*, em datas a serem fixadas pelo seu Presidente, observando-se os prazos regimentais, o qual **opinará** pela *aprovação* ou *rejeição* da indicação e, em seguida, submeterá a indicação à **decisão do Plenário**.

Como se disse, pela regra constitucional, o nome indicado deverá ter a aprovação da **maioria absoluta dos membros do Senado Federal** (Plenário).

Havendo rejeição de qualquer nome pelo Plenário do Senado Federal será oficiado à autoridade máxima do órgão ou instituição competente para a indicação, a fim de que novo nome seja apresentado no prazo improrrogável de 15 dias.

Os **critérios** para a escolha dos membros que compõem o CNMP foram regulamentados **apenas** para os **membros do Conselho oriundos do Ministério Público** (cf. art. 130-A, § 1.º, da CF/88 e Lei n. 11.372/2006).

Inexiste, contudo, critério normativo para a indicação dos demais membros que não sejam os oriundos do Ministério Público, no caso pelo STF, STJ, CFOAB, CD e SF (*vide* quadro *infra*).

Entendemos imprescindível haver uma definição normativa da indicação de todos os membros, especialmente em razão da importância que referido Conselho vem assumindo.

De toda forma, as indicações de nomes deverão ser acompanhadas de amplos esclarecimentos sobre o candidato e instruídas com os seguintes documentos **(art. 5.º da Res. n. 7/SF-2005)**:

- *curriculum vitae* do indicado no qual conste, detalhadamente, sua qualificação, formação acadêmica e experiência profissional;
- informação do indicado de que não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de membro ou servidor do Poder ou instituição responsável por sua indicação, salvo, no caso de servidor, se for ocupante de cargo de provimento efetivo e, observada esta condição, não servir junto à autoridade a que esteja vinculado pelo parentesco mencionado;
- declaração sobre eventual cumprimento de sanções criminais ou administrativo-disciplinares, bem como acerca da existência de procedimentos dessa natureza instaurados contra o indicado;
- declaração do indicado de que não é membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de membro desses Poderes.

■ **12.2.10.5. Esquematização gráfica sobre a indicação dos membros do CNMP**

O quadro abaixo esquematiza a **indicação dos membros** que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público, destacando-se as seguintes regras:

- **art. 103-A, I**: será presidido pelo PGR;
- **art. 103-A, § 3.º**: escolherá um Corregedor Nacional dentre os membros do Ministério Público;
- **art. 130-A, § 4.º**: o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos

- **mandato:** expirará juntamente com seu mandato de Conselheiro;

- **funções:** serão exercidas pelo Corregedor Nacional em regime de **dedicação exclusiva**, ficando afastado do órgão do Ministério Público a que pertence.

Competem ao Corregedor Nacional, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei ou pelo Regimento Interno do CNMP (cf. art. 18 do *RICNMP*), as seguintes (art. 130-A, § 3.º, da CF/88):

- receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

- exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

- requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições;

- requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

■ **12.2.10.7. Atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)**

É da competência do Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe (art. 130-A, § 2.º, I a V, da CF/88):

- zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

- zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do

Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

- rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros [38](#) do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano;

- elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

Interessante destacar o **Enunciado n. 8, de 04.04.2014, do CNMP**, afastando a atuação do Conselho em relação a questões de **caráter meramente individual**, tendência essa também verificada no CNJ e por orientação do STF.

Nesse sentido, ficou expresso não caber “ao Conselho Nacional do Ministério Público o exame de pretensões que ostentem natureza meramente individual, que não ultrapassem o interesse subjetivo das partes envolvidas, mostrando-se desprovidas de repercussão geral para a sociedade ou para o Ministério Público”.

Pelo enunciado, “pressupõe-se a repercussão geral da demanda que esteja relacionada a função eminentemente institucional do Ministério Público ou que tenha natureza disciplinar dos seus membros”.

O referido enunciado, buscando afastar qualquer surpresa, já que se tratava de alteração da orientação estabelecida até então, determinou que a sua aplicação somente se daria para os feitos protocolizados no Conselho após a sua publicação, que ocorreu no *DOU* de 02.05.2014.

- **12.2.10.8. Pode o CNMP fixar novo teto remuneratório dos membros e servidores do Ministério Público diferente do estabelecido na CF/88?**

Não.

A Res. n. 15, de 04.12.2006, do CNMP alterou o teto remuneratório dos membros do MP de 90,25% para 100% do subsídio de Ministros do STF.

O PGR ajuizou a **ADI 3.831** atacando a referida Res. n. 15/2006 do CNMP, que, conforme visto, alterando os arts. 1.º e 2.º da Res. n. 9/2006 e o art. 2.º da Res. n. 10/2006, ambas do CNMP, equiparava o teto remuneratório dos membros e servidores do Ministério Público da União e dos Estados aos dos Ministros do STF.

Em julgamento cautelar, o STF entendeu que a Res. n. 15/2006 citada, “... a princípio, ofende os arts. 37, X, XI, § 12, e 130-A, § 2.º, todos da CF, porquanto não observa o princípio da legalidade específica para a definição dos valores a serem pagos a título de remuneração ou subsídio dos agentes públicos, bem como extrapola os limites tanto de subsídio e remuneração previstos para os membros e servidores do Ministério Público dos Estados — 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF — quanto de competência do CNMP” (ADI 3.831-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15.12.2006 — *Inf. 452/STF*).

A Suprema Corte, em **04.06.2007**, tendo em vista a revogação da Res. n. 15/2006, pela Res. n. 17/2007, declarou prejudicada a ADI.

■ **12.2.10.9. O CNMP tem competência para realizar controle de constitucionalidade no exercício de suas atribuições?**

O tema ainda não foi enfrentado pelo Plenário do STF (pendente), mas devemos destacar a orientação da 1.ª Turma do STF **não admitindo o controle de constitucionalidade pelo CNMP**, mesmo que no caso concreto e de modo incidental.

Conforme informado, “a Turma asseverou que o CNMP não ostentaria competência para efetuar controle de constitucionalidade de lei, haja vista se tratar de **órgão de natureza administrativa**, cuja atribuição se circunscreveria ao **controle da legitimidade dos atos administrativos** praticados por membros ou órgãos do Ministério Público federal e estadual (CF, art. 130-A, §

2.º). Assim, o CNMP, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141, 'in fine', da Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina (...) teria **exorbitado de suas funções**, que se limitariam ao **controle de legitimidade dos atos administrativos** praticados por membros do 'parquet'" (*Inf. 781/STF*, **MS 27.744**, j. 14.04.2015 — acórdão não publicado até a data de fechamento desta edição).

Parece-nos, contudo, que, no **caso concreto**, de **modo incidental**, desde que se trate de ato **flagrantemente inconstitucional**, o CNMP poderia declarar a inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo, em verdadeiro controle difuso e na linha do estabelecido para o TCU, nos termos da S. 347/STF (lembramos que esse tema também está em discussão no STF — cf. *item 11.13.5.3*).

■ 12.2.10.10. Outras regras

O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil terá assento e voz no Plenário, podendo se fazer representar em suas sessões por membro da Diretoria do Conselho Federal da entidade (art. 4.º, parágrafo único, do *RICNMP*).

Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Destacamos, ainda, a competência do **Senado Federal** para processar e julgar os membros do Conselho nos **crimes de responsabilidade** e a competência do **STF** para julgar as **ações** contra o Conselho (arts. 52, II, e 102, I, "r").

Finalmente, em relação às **infrações penais comuns**, assim como já visto em relação ao CNJ, a **competência** será fixada **individualmente**, de acordo com o cargo de origem de cada membro do Conselho, lembrando que a *PEC Paralela da Reforma do Judiciário (PEC n. 358/2005)*, que precisa ainda ser aprovada, estabelece a competência do STF, mas isso, como se disse, depende de

aprovação pelo CN.

■ 12.2.11. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (art. 130)

O **art. 130** estatui que aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições pertinentes a **direitos**, **vedações** e **forma de investidura** estabelecidas para o Ministério Público, como instituição, aqui já estudadas por nós.

Referida instituição será organizada por **lei orgânica própria** e de **iniciativa do Tribunal de Contas**, sendo materializada por meio de **lei ordinária**.

Diferentemente, apenas para fazer o contraponto, o art. 128, § 5.º, estatui que **leis complementares** (e não leis ordinárias) da União e dos Estados, cuja iniciativa é **facultada** aos respectivos Procuradores-Gerais (e já vimos que também é facultativamente ao Presidente da República — art. 61, § 1.º, II, “d” — cf. *item 9.13.3.7.1*), estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.

Portanto, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas está estruturalmente ligado ao Tribunal de Contas da União ou do Estado (ou do Município, onde houver), e não ao Ministério Público da União, ou dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, devendo ser entendido como uma **instituição autônoma**.³⁹

Conforme já estudamos, “o **Ministério Público especial** junto aos Tribunais de Contas — que configura uma indiscutível realidade constitucional — qualifica-se como órgão estatal dotado de identidade e de fisionomia próprias que o tornam inconfundível e inassimilável à instituição do Ministério Público comum da União e dos Estados-membros. Não se reveste de legitimidade constitucional a participação do Ministério Público comum perante os Tribunais de Contas dos Estados, pois essa participação e atuação acham-se constitucionalmente reservadas aos membros integrantes do Ministério Público especial, a que se refere a própria Lei Fundamental da República (art. 130). O preceito consubstanciado no art. 130 da Constituição reflete uma solução de

compromisso adotada pelo legislador constituinte brasileiro, que preferiu não outorgar, ao Ministério Público comum, as funções de atuação perante os Tribunais de Contas, optando, ao contrário, por atribuir esse relevante encargo a agentes estatais qualificados, deferindo-lhes um *status* jurídico especial e ensejando-lhes, com o reconhecimento das já mencionadas garantias de ordem subjetiva, a possibilidade de atuação funcional exclusiva e independente perante as Cortes de Contas” (**ADI 2.884**, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 20.05.2005 — cf., também, **ADI 3.192**, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.05.2006, *DJ* de 18.08.2006).

Conforme já destacamos no *item 9.15.5*, no julgamento da *Consulta n. 0.00.000.000843/2013-39*, formulada pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), o **Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)** entendeu que o **Ministério Público de Contas (MPC)** e seus **membros** estão sujeitos ao seu controle administrativo, financeiro e disciplinar:

“Consulta respondida positivamente para reconhecer ao Ministério Público de Contas a **natureza jurídica de órgão do Ministério Público brasileiro** e, em consequência, a competência do CNMP para zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos respectivos membros e pela garantia da autonomia administrativa e financeira das unidades, controlando os atos já praticados de forma independente em seu âmbito, e adotando medidas tendentes a consolidar a parcela de autonomia de que ainda carecem tais órgãos” (j. 07.08.2013 — *tema pendente de análise pelo STF*).

Apesar da resposta dada pelo CNMP, muito embora tenha sido afirmado que o MPC apresenta natureza jurídica de órgão do MP brasileiro, não poderá haver o aproveitamento de membros de uma carreira na outra, como já vinha decidindo o STF.

Cabe lembrar que essa decisão proferida pelo CNMP serviu, entre outros fundamentos, para o encaminhamento da **PEC n. 42/2013-SF** (*pendente*), que propõe a alteração do art. 130-A para deixar claro que o MPC e os seus membros se sujeitam ao controle do CNMP.

CUIDADO: o então Senador da República Pedro Taques, relator da PEC,

encaminhou ofício ao CNMP solicitando a manifestação sobre a referida proposta de alteração da Constituição.

Diante desse requerimento, o Conselho editou a *Nota Técnica n. 5, de 28.01.2015 (DOU de 25.02.2015 — processo n. NT 0.00.000.000008/2014-80)*, **revendo** a decisão proferida em 2013 que estabelecia estar o Ministério Público de Contas sujeito à competência do CNMP, seguindo, inclusive, a nota técnica PGR/SRI n. 004/2013, de 28.10.2013, emitida pelo PGR, todas no sentido de expressar a contrariedade à alteração da Constituição nos termos da referida proposta que não altera a redação do art. 128.

O CNMP, contudo, deixa clara, na *nota técnica*, a possibilidade de “manifestação favorável **caso o Ministério Público de Contas seja plena e expressamente integrado ao regime constitucional previsto para o Ministério Público**, com a sua **inclusão nos segmentos previstos no art. 128 da Constituição**, inclusive com o acréscimo de parágrafos para explicitar a sua organização, o seu funcionamento e a sua forma de escolha e destituição das suas chefias, além da previsão de lei complementar instituindo-lhe um estatuto, em que seja assegurada a sua autonomia funcional, administrativa, orçamentária, financeira e disciplinar, sem qualquer submissão ao Tribunal de Contas junto ao qual atue”.

■ 12.3. ADVOCACIA PÚBLICA

■ 12.3.1. A distorção corrigida pela EC n. 19/98

O texto de 1988 abre uma seção própria, dentro do capítulo *das funções essenciais à Justiça*, para tratar da **advocacia pública** e **explicita** regras para a *Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal*.

O constituinte originário denominou **equivocadamente** a *Seção II do Capítulo IV do Título IV*, em sua redação original, ao se referir apenas a *Advocacia-Geral da União*.

Isso porque, além de a *Seção* conter informações sobre os *Procuradores dos Estados* e do *Distrito Federal*, o entendimento de **advocacia pública** deve englobar, naturalmente, os advogados das **autarquias** e **fundações**.

Tanto é assim que o art. 29, *caput*, do ADCT estabeleceu que, enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, o **Ministério Público Federal**,⁴⁰ a **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, as **Consultorias Jurídicas dos Ministérios**, as **Procuradorias** e **Departamentos Jurídicos de autarquias federais** com representação própria e os membros das **Procuradorias das Universidades fundacionais públicas** continuariam a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições.

Essa distorção veio a ser corrigida pela **EC n. 19/98**, que alterou o nome da referida Seção para **Advocacia Pública**, de maneira acertada, agora.

Não houve previsão explícita de *Procuradorias Municipais*, podendo, naturalmente e desde que observadas as regras constitucionais, a matéria ser tratada nas Constituições Estaduais, Leis Orgânicas e legislação própria.⁴¹

■ 12.3.2. O advogado público pode exercer a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo?

Diante da timidez do constituinte de 1988 em relação à *Seção da Advocacia* (timidez perto do detalhamento da *Seção* que tratou do *Ministério Público*), muitas regras foram destinadas ao *legislador infraconstitucional*, motivo por que os *concurseiros* (“ilustres guerreiros”) deverão estudar, de modo aprofundado, as leis orgânicas de cada carreira, sobretudo, no âmbito da *Administração Federal* (direta, autárquica e fundacional) (área jurídica) as de:

- **Advogado da União;**
- **Procurador da Fazenda Nacional;**
- **Procurador Federal;**
- **Procurador do Banco Central do Brasil.**

Para se ter ideia da dimensão do regramento por norma infraconstitucional, indaga-se, por exemplo (e isso mostra a particularidade de cada carreira, devendo o estudo ser desenvolvido de acordo com a necessidade de cada um), se seria possível o *advogado público* **advogar** fora da carreira. Ou seja, será que um **advogado público** pode exercer a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo?

Em âmbito constitucional, nada consta. Assim, **cabe às leis de organização de cada carreira disciplinar a matéria.**

A título de informação, as duas únicas previsões proibindo a advocacia *fora das atribuições institucionais* foram estabelecidas para a **defensoria pública** (que, apesar de ser *pública*, não pode ser colocada no conceito de *advocacia pública*, pois não atua em nome de ente estatal, mas do hipossuficiente — cf. art. 134, § 1.º) e para o **Ministério Público**, com as ressalvas já apresentadas (art. 128, § 5.º, II, “b”, da CF/88 e art. 29, *caput*, e § 2.º, do ADCT, bem como o item 12.2.7.3), que também está longe de ser alocado como *advocacia pública*, especialmente em razão do alargamento de suas funções no novo ordenamento, da sua evolução e de sua consagração como instituição permanente e verdadeiro **advogado da sociedade**.

Portanto, teoricamente, e **desde que não haja proibição legal** (visto que não houve previsão constitucional), os **advogados públicos** poderão advogar fora das atribuições institucionais desde que **não violem os interesses da pessoa de direito público em relação à qual pertençam**. Assim, resta investigar o que disciplinou a lei para cada carreira. Vejamos:

ADVOGADOS PÚBLICOS	PODEM EXERCER A ADVOCACIA FORA DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS?
ADVOGADOS DA UNIÃO	■ NÃO ■ art. 28, I, da LC n. 73/93

PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL	■ NÃO ■ os <i>Procuradores da Fazenda Nacional</i> são considerados membros da Advocacia-Geral da União ■ arts. 2.º, § 5.º, e 28, I, da LC n. 73/93
PROCURADORES FEDERAIS	■ NÃO ■ os <i>Procuradores Federais</i> são advogados públicos vinculados à <i>Advocacia-Geral da União</i> ■ arts. 2.º, § 3.º, 17 e 28, I, da LC n. 73/93 ■ art. 38, § 1.º, I, da MP n. 2.229-43, de 06.09.2001 (em vigor por força do art. 2.º da EC n. 32/2001)
PROCURADORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	■ NÃO ■ os <i>Procuradores do Banco Central</i> são advogados públicos vinculados à <i>Advocacia-Geral da União</i> ■ arts. 2.º, § 3.º, 17 e 28, I, da LC n. 73/93 ■ art. 17-A, I, da Lei n. 9.650/98 (incluído pela MP n. 2.229-43, de 06.09.2001, em vigor por força do art. 2.º da EC n. 32/2001)
PROCURADORES DOS ESTADOS	■ DEPENDE ■ conforme visto, como não há previsão constitucional, a definição ficou ao encargo das Constituições Estaduais e leis orgânicas. Não havendo proibição, poderão advogar
	■ SIM ■ não há vedação, seja na Lei Orgânica do DF, seja na LC n.

PROCURADORES DO DF	395/2001 (lei distrital que organiza a Procuradoria-Geral do Distrito Federal) ■ cuidado: o art. 28, III, do <i>Estatuto da Advocacia</i> (Lei n. 8.906/94) estabelece que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, em relação aos ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público
PROCURADORES DE MUNICÍPIOS	■ DEPENDE ■ conforme visto, como não há previsão constitucional, a definição ficou ao encargo das Constituições Estaduais e leis orgânicas. Não havendo proibição, poderão advogar

■ 12.3.3. Assessoramento, amplitude vinculativa dos pareceres jurídicos e a responsabilização dos advogados públicos

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello classifica os pareceres em *facultativos*, *obrigatórios* e *vinculantes*:[42](#)

■ **parecer facultativo:** “consiste em opinião emitida por solicitação de órgão ativo ou de controle, **sem que qualquer norma jurídica determine sua solicitação**, como preliminar à emanção do ato que lhe é próprio. Por outro lado, fica a seu critério adotar, ou não, o pensamento do órgão consultivo. Consiste, destarte, em exercício de poder **discricionário** quanto ao **pedido**, e à **efetivação** do ato relativamente ao **parecer**. Este, portanto, externamente, não tem relevância jurídica, **salvo se o ato a ele se reportar**”. Ou seja, o parecer só integrará a decisão se for indicado como seu fundamento, passando, então, a corresponder à própria motivação;

■ **parecer obrigatório:** “consiste em opinião emitida por solicitação de órgão ativo ou de controle, **em virtude de preceito normativo que**

prescreve sua solicitação, como preliminar à emanção do ato que lhe é próprio. Constituem a consulta e o parecer fases necessárias do procedimento administrativo. (...). O ato praticado sem dito pronunciamento estará eivado de vício de nulidade, por desrespeito a solenidade essencial. A obrigação, entretanto, é só de pedir o parecer, jamais de segui-lo, de emanar o ato ativo ou de controle segundo sua manifestação. O desrespeito ao parecer não invalida o ato; poderá, quando muito, se injustificável a orientação em contrário, sujeitar o órgão ativo ou de controle às consequências de responsabilidade administrativa, após regular apuração”;

■ **parecer conforme ou vinculante**: “é o que a Administração Pública **não só deve pedir** ao órgão consultivo, como **deve segui-lo** ao praticar ato ativo ou de controle. Encerra regime de exceção, e só se admite quando expressamente a lei ou o regulamento dispõem nesse sentido. O ato levado a efeito em desconformidade com o parecer se tem como **nulo**”. Como exemplo, podemos citar a decisão da administração sobre o pedido de **aposentadoria por invalidez** que tem de seguir exatamente a conclusão do médico oficial.

A **advocacia pública**, vale repetir, de modo geral, tem tanto o papel de **representação judicial** como de **consultoria** e **assessoramento** dos entes e entidades da administração direta e indireta.

Em relação ao **assessoramento**, importante distinção foi feita pelo Min. Joaquim Barbosa no tocante à vinculação ou não dos **pareceres jurídicos** e da **responsabilização** do advogado público. Vejamos:[43](#)

■ **consulta facultativa**: “... a autoridade **não se vincula** ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo”;

■ **consulta obrigatória**: “... a autoridade administrativa **se vincula** a emitir o **ato** tal como submetido à **consultoria**, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer”;

■ **obrigação de decidir à luz de parecer vinculante em razão de**

previsão legal: “... essa manifestação de teor jurídico deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão **nos termos da conclusão do parecer** ou, então, não decidir”;

■ **responsabilização:** “(...) II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua **natureza opinativa**, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é **abusiva a responsabilização do parecerista** à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. **Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa...**”.

Assim, em referido precedente (que data de 09.08.2007), o Min. Relator entendeu que, sendo o parecer **opinativo**, não haverá vinculação do advogado público.

Porém, lendo o acórdão, afirma Joaquim Barbosa que se o parecer for **vinculante** há “**partilha do poder decisório**” (...) “e assim, em princípio, o parecerista pode vir a ter que responder conjuntamente com o administrador, **pois ele é também administrador nesse caso**” (fls. 285 e 286 do acórdão — grifamos).

Com o máximo respeito, na linha da manifestação de Carlos Britto no mesmo acórdão, não concordamos que o parecerista, pelo simples fato de atuar no processo administrativo, se transforme em administrador.

Ainda, em razão das garantias de independência que devem ser asseguradas aos advogados públicos para que não sofram pressões políticas, a nosso ver essa responsabilização não pode ser automática.

Em nosso entender, e a matéria precisa ser mais bem definida pelo STF, a responsabilização dependeria de demonstração de erro grosseiro, falta grave, má-fé, sob pena de se esvaziar a amplitude que devem ter os pareceres jurídicos

das consultorias.

Para Di Pietro, a responsabilização “... não se justifica se o parecer estiver adequadamente fundamentado; a simples diferença de opinião — muito comum na área jurídica — não pode justificar a responsabilização do consultor. Não é por outra razão que o parecer isoladamente não produz qualquer efeito jurídico; em regra, ele é meramente opinativo”.[44](#)

Nesse sentido, existe importante precedente do STF, anterior ao julgamento do referido MS 24.631, pelo qual a Corte **não admite a automática responsabilização solidária do advogado público ao emitir parecer jurídico**, o que parece ser, naturalmente, o melhor entendimento **(matéria pendente de aprofundamento pelo STF)**:

“EMENTA: (...). Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta: **impossibilidade**, dado que o **parecer não é ato administrativo**, sendo, quando muito, **ato de administração consultiva**, que visa a **informar, elucidar, sugerir** providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa (...). II — O advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de **erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo**: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32. III — Mandado de Segurança deferido” (**MS 24.073**, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 06.11.2002, Plenário, *DJ* de 31.10.2003).

■ 12.3.4. *Contempt of Court*: a multa do art. 14, parágrafo único, do CPC/73 e os advogados públicos — ADI 2.652. CPC/2015 — avanço na linha da decisão do STF

O art. 14, parágrafo único, do CPC/73, introduzido pela Lei n. 10.358, de 27.12.2001, buscou estabelecer mecanismos para evitar o *contempt of court* (bem diferente do sistema norte-americano, que inspirou a regra).

No fundo, procura-se encontrar uma forma de fazer cumprir, com exatidão, os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

Para tanto, optou-se pela possibilidade de o juiz fixar **multa**, de até 20% do valor da causa, em caso de violação do art. 14, V, do CPC/73, que, contudo, **não será aplicada aos advogados**.

A dúvida consistia em saber se a não aplicação da multa se restringia aos advogados que se sujeitam exclusivamente ao Estatuto da OAB, ou também aos advogados públicos, até porque a literalidade da redação dava a entender que a regra era exclusiva dos advogados não públicos. Confira:

“Art. 14, V: São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: cumprir com exatidão os **provimentos mandamentais** e **não criar embaraços** à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

Parágrafo único. **Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB**, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável **multa** em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a **20%** do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”.

A falta de uma *vírgula* depois da palavra “ressalvados” dava a entender que seriam apenas os *advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB*, lembrando que os **advogados públicos** se sujeitam às suas leis orgânicas e, também, mas não somente, aos estatutos da OAB.

Todavia, o STF deu interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, e fixou que a ressalva do art. 14, parágrafo único, do CPC/73 “... alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (*Inf. 307/STF*). Nesse sentido:

‘EMENTA: Impugnação ao parágrafo único do art. 14 do CPC/73, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de *multa por obstrução à Justiça*. Discriminação em relação aos **advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade**. Violação ao **princípio da isonomia** e ao da **inviolabilidade no exercício da profissão**. Interpretação adequada, para afastar o injustificado *discrímen*. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do art. 14 do CPC/73 conforme a CF e declarar que a **ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos**’.⁴⁵

Esse correto entendimento estabelecido pelo STF está preservado e explicitado no **CPC/2015** (Lei n. 13.105/2015). De acordo com o art. 77, § 6.º, aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2.º a 5.º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

■ 12.3.5. Pareceres e Súmula da Advocacia-Geral da União

O art. 39 da LC n. 73/93 considera **privativo** do Presidente da República o direito de submeter assuntos ao exame do Advogado-Geral da União, inclusive para seu **parecer**.

Os pareceres do Advogado-Geral da União são por ele submetidos à aprovação do Presidente da República (arts. 39 a 44 da LC n. 73/93):

■ **parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial:** “vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento”;

■ **parecer aprovado, mas não publicado:** “obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência”;

■ **pareceres emitidos pela Consultoria-Geral da União:** “consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República”;

■ **pareceres das Consultorias Jurídicas:** “aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas”;

■ **Súmula da Advocacia-Geral da União:** “súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2.º e 17 da LC n. 73/93”.

■ 12.3.6. Advocacia-Geral da União

■ 12.3.6.1. Regras gerais

Antes das novas regras trazidas pela CF/88 (*vide item 12.2.1.8*), a **representação judicial da União** (administração direta) competia ao **Ministério Público Federal**, podendo, por força da EC n. 1/69, a União ser representada pelo **Ministério Público estadual** nas comarcas do interior.

Por sua vez, o **Decreto n. 93.237/86** regulava as atividades de **advocacia consultiva** da União, no Poder Executivo, tendo sido a **Consultoria-Geral da República** erigida à instância máxima das atividades de **consultoria** e **assessoramento** jurídicos da Administração Federal.

Nesses termos, o art. 3.º do referido Decreto **estabelecia** que a **Advocacia Consultiva da União** compreendia: **a)** a Consultoria-Geral da República; **b)** a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Ministério da Fazenda; **c)** as Consultorias Jurídicas dos demais Ministérios, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República; **d)** as

Procuradorias-Gerais ou os departamentos jurídicos das autarquias; **e**) os órgãos jurídicos das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações sob supervisão ministerial e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União.

Com a promulgação da Constituição de 1988, a **Advocacia-Geral da União** (AGU), cujo **ingresso** nas classes iniciais das carreiras far-se-á mediante **concurso público de provas e títulos**, passou a ser a instituição que, **diretamente** ou por meio de **órgão vinculado**, representa a União, **judicial** e **extrajudicialmente**, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar⁴⁶ que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de **consultoria** e **assessoramento jurídico** do **Poder Executivo** (art. 131, *caput*).⁴⁷

Devemos observar, conforme já tanto mencionado, que, por força do art. 29, *caput*, do ADCT, o **MPF** continuou **representando a União** até a aprovação da **LC n. 73/93** (que institui a *Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União*), devendo os Procuradores da República optar, de forma **irretratável**, entre as carreiras do **MPF** e da **AGU** (cf. art. 29, § 2.º, do ADCT; art. 61 da LC n. 73/93 e art. 282 da LC n. 75/93).

Deve-se deixar bem claro que a **representação judicial e extrajudicial** é da **União**, englobando, assim, os seus diversos órgãos, em **quaisquer dos Poderes**. Por exemplo, o CNJ, órgão do Poder Judiciário (art. 92, I-A), será representado pela **AGU** nas ações originárias que tramitam no STF.⁴⁸

Por outro lado, as atividades de **consultoria** e **assessoramento jurídico** foram previstas **apenas** para o **Poder Executivo**. Vejamos o quadro para facilitar a memorização:

representação judicial e extrajudicial	■ diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (UNIÃO)
■ consultoria e assessoramento jurídico	■ apenas do Poder Executivo

■ 12.3.6.2. Órgãos da Advocacia-Geral da União

Os **Órgãos da Advocacia-Geral da União** estão previstos no art. 2.º da LC n. 73/93, e as suas características deverão ser aprofundadas pelos *ilustres leitores* que se preparam para os respectivos cargos (analisando, portanto, detidamente, a *Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União*).

Para efeito deste estudo, limitamo-nos a destacar os referidos órgãos:

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR	■ Advogado-Geral da União ■ Procuradoria-Geral da União ■ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ■ Consultoria-Geral da União ■ Conselho Superior da Advocacia-Geral da União ■ Corregedoria-Geral da Advocacia da União
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO	■ Procuradorias Regionais da União ■ Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional ■ Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais destas ■ Procuradorias da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais destas ■ Consultoria da União

	■ Consultorias Jurídicas nos Ministérios
ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO	■ Gabinete do Advogado-Geral da União
ÓRGÃOS VINCULADOS	■ Procuradorias e Departamentos Jurídicos das autarquias e fundações públicas

■ 12.3.6.3. Advogado-Geral da União

O **Chefe** da Advocacia-Geral da União é o **Advogado-Geral da União (AGU)**, em relação ao qual temos as seguintes regras:

- **nomeação:** o AGU é de **livre nomeação** pelo **Presidente da República** (art. 84, XVI);
- **exoneração:** por ser o cargo de **livre nomeação** pelo Presidente da República, trata-se de **cargo de confiança** e, portanto, também de **livre exoneração**. Assim, pode-se afirmar que o AGU é **demissível ad nutum**;
- **requisitos:** o AGU será escolhido dentre cidadãos maiores de **35 anos**, de **notável saber jurídico** e **reputação ilibada**;
- **poderá ser estranho à carreira:** por ser de **livre nomeação**, o **AGU** poderá ser **estranho à carreira da advocacia pública**, o que, em nosso entender, não parece ser a melhor solução;
- **status de Ministro de Estado:** de acordo com o art. 25, parágrafo único, da Lei n. 10.683/2003 (na redação dada pela Lei n. 12.462/2011), o *Advogado-Geral da União* tem *status* de **Ministro de Estado**; [49](#)
- **infrações penais comuns:** o AGU, por ser considerado **Ministro de Estado** (art. 25, parágrafo único, da Lei n. 10.683/2003), será julgado pelo **STF** nas infrações penais comuns;
- **crime de responsabilidade:** o AGU será processado e julgado nos

crimes de responsabilidade pelo **Senado Federal** (art. 52, II);

■ **delegação de atribuições do Chefe do Executivo:** de acordo com o art. 84, parágrafo único, da CF/88, o Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte (do referido art. 84), além dos Ministros de Estado e do Procurador-Geral da República, para o **Advogado-Geral da União**, devendo ser observados os limites traçados nas respectivas delegações;

■ **direito de “manifestação” no controle concentrado de constitucionalidade:** em razão da importância do assunto, desenvolvemos a discussão no *item 12.3.6.4* abaixo, chegando à conclusão de que o AGU não tem necessariamente de defender a lei quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo. O dever que o texto lhe impõe é de **manifestação**, mitigando-se, assim, a sua função de “defensor *legis*”, que passa a ser repensada à luz de um conceito mais amplo, de “*custos constitutionis*”;

■ **supervisão do Presidente da República:** o art. 3.º, § 1.º, da LC n. 73/93 estabelece que o Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à **direta, pessoal e imediata** supervisão do Presidente da República.

■ **12.3.6.4. O caso particular do “direito de manifestação” do AGU no controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, § 3.º)**

De acordo com o art. 103, § 3.º, da CF/88, quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que **defenderá** o ato ou texto impugnado.

A grande questão que se coloca é se, de fato, o AGU tem o dever de “defender” o texto impugnado, ou se há alguma flexibilidade na literalidade da norma.

Como já indicamos no capítulo sobre “controle” (*item 6.7.1.15*), a jurisprudência do STF sofreu importante evolução:

■ **ADI 72** — *j. 22.03.90*: enfrentado o tema, o STF posicionou-se, em um primeiro momento, como sendo obrigatória a defesa da lei por parte do AGU: [50](#)

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Advogado-Geral da União: **Indeclinabilidade** da defesa da lei ou ato normativo impugnado (cf. art. 103, par. 3.). Erigido **curador da presunção da constitucionalidade da lei**, ao Advogado-Geral da União, ou quem lhe faça as vezes, **não cabe admitir a invalidez da norma impugnada**, incumbindo-lhe sim, para satisfazer requisitos de validade do processo da ação direta, **promover-lhe a defesa**, veiculando os argumentos disponíveis”.

■ **ADI 1.616** — *j. 24.05.2001*: a jurisprudência do STF começa a evoluir, permitindo que o AGU deixe de defender o texto impugnado se já houver manifestação (precedente) do STF: [51](#)

“EMENTA: (...) 4. O *munus* a que se refere o imperativo constitucional (CF, artigo 103, § 3.º) deve ser entendido com temperamentos. O Advogado-Geral da União **não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade** (...)”.

■ **ADI 3.916-QO** — *j. 07.10.2009*: a matéria veio a ser rediscutida e em **maior profundidade**. O Tribunal, por maioria, **rejeitou** a questão de ordem no sentido de suspender o julgamento para determinar ao Advogado-Geral da União que necessariamente apresentasse defesa da lei impugnada, nos termos do art. 103, § 3.º, da CF/88, vencidos os Ministros Marco Aurélio (suscitante) e Joaquim Barbosa. Com base na **interpretação sistemática**, o STF entendeu que o AGU tem o **direito de manifestação**, não necessariamente a favor da lei, mas na **defesa da Constituição** e, assim, dos **interesses da União** (art. 131). Ademais, uma questão prática pesou para esse entendimento, qual seja, a **inexistência de sanção** prevista na Constituição em caso de não ser defendida a lei, inclusive de caráter processual, já que, mesmo que o AGU não se manifeste a favor da lei, essa sua atitude não acarretaria a nulidade processual ou o impedimento de julgamento da matéria.

Coletando passagens do julgamento, de fato, o AGU tem a atribuição de exercer o papel de **contraditor do processo objetivo**, mas, como visto, não se lhe pode causar um **constrangimento** se a sua convicção jurídica for outra.

Para o Min. Ayres Britto, “... a Advocacia-Geral da União defenderá o ato ou o texto impugnado quando possível, quando viável”.

A tese a favor da **liberdade de atuação** fica muito mais evidente quando se tratar de *vício formal de inconstitucionalidade*, pois, nesse caso, não poderia o AGU funcionar como advogado de lei inconstitucional, já que, em essência, deve-se pautar pela **defesa da Constituição**.

Segundo a Min. Cármen Lúcia, a expressão “defenderá” prevista no art. 103, § 3.º, deve ser interpretada como a **manifestação** na qual se apresentará a *argumentação que lhe parecer mais adequada*.

Nesse sentido, o art. 8.º da Lei n. 9.868/99 dispõe que, decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão **manifestar-se**, cada qual, no prazo de 15 dias, não se referindo, a lei, ao conteúdo dessa manifestação. Trata-se, frisamos, do *direito de manifestação*.

Ainda, para o Min. Ayres Britto, “... não se pode constranger o Advogado-Geral da União a ponto de, para defender o ato atacado, **agredir a própria Constituição**; ou seja, ele sairá em defesa da lei menor e em combate da Lei Maior, porque há situações em que a inconstitucionalidade é patente, é evidente”.

Assim, dada a gravidade que é a retirada de uma lei do ordenamento por ato jurisdicional contra ato legislativo, cujos “atores” foram diretamente escolhidos pelo povo, de fato, o **contraditor** é o **Advogado-Geral da União**.

Conforme visto, porém, se já houver pronunciamento do STF, ou se a defesa da lei acabar violando a Constituição, parece razoável a interpretação do STF de que tem o AGU o **direito de manifestação**, não precisando passar pelo constrangimento de defender o ato normativo contrário à Constituição.

ADI 3.413 — *j. 01.06.2011*: nesse outro julgamento, posterior, portanto, à questão de ordem na ADI 3.916 (que avançou ao consagrar o denominado

“direito de manifestação” do AGU), a ementa do acórdão foi explícita ao estabelecer o dever de defender o texto impugnado, mesmo tendo sido a justificativa do AGU com base em precedentes da Corte, na linha da ADI 1.616. Conforme se observa, o Relator foi o Min. Marco Aurélio, vencido na citada ADI 3.916, em que se firmou o posicionamento mais aberto: [52](#)

“Consoante dispõe a norma imperativa do § 3.º do art. 103 da CF, **incumbe** ao Advogado-Geral da União **a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade**, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade”.

Diante do exposto, entendemos que o STF deveria enfrentar o tema na composição atual, para se ter um posicionamento mais firme. Para esquematizar melhor a matéria, transcrevemos as 3 situações apontadas em entrevista concedida pelo Advogado-Geral da União, Luís Inácio Lucena Adams, nas quais, segundo a sua opinião (institucional), haveria o afastamento da regra rígida de se defender o texto impugnado — art. 103, § 3.º, CF/88 (lembrando que o Min. Marco Aurélio é categórico em não aceitar qualquer ressalva):

■ **existência de posicionamento anterior do Supremo sobre o tema:**

“é comum acontecer nos casos de guerra fiscal. O Supremo tem reiteradamente decidido que leis que concedem benefícios fiscais nos estados têm que ter a aprovação do Confaz — Conselho Nacional de Política Fazendária. Se não tiver, é inconstitucional. Isso autoriza o Advogado-Geral a não defender a lei. Nesse caso, o próprio Estado se faz presente como *amicus curiae*”;

■ **sobreposição de competência normativa:** “quando um Estado aprova uma lei sobre assunto em que a competência concorrente é da União. Se o Estado avançar sobre a competência da União, temos de fazer a opção. Há ocasiões em que não há como defender as duas normas”;

■ **interpretação da lei conforme a Constituição sem redução de texto:** “ou seja, quando há mais de uma forma de se interpretar uma lei. Aí a AGU faz a opção quanto ao lado em que vai atuar, porque a lei não vai ser eliminada do mundo jurídico”. [53](#)

■ 12.3.6.5. *Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional*

A Constituição estabeleceu que, na **execução da dívida ativa de natureza tributária**, a **representação da União** caberá à **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)**.

Dessa forma, com o novo ordenamento, a PGFN deixou de ter vinculação exclusiva com o Ministério da Fazenda, passando a ser **órgão de direção superior** da nascente **Advocacia-Geral da União**, e se subordinando **direta, técnica e juridicamente** ao **Advogado-Geral da União** (art. 2.º, I, “b”, e § 1.º, da LC n. 73/93).

À *Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional* **competete** especialmente (arts. 12 e 13 da LC n. 73/93):[54](#)

- apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, **amigável** ou **judicial**;
- representar privativamente a União, na **execução de sua dívida ativa de caráter tributário**;
- examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao **Ministério da Fazenda**, inclusive os referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou judicial;
- representar a União nas causas de **natureza fiscal**;
- desempenhar as atividades de **consultoria** e **assessoramento jurídicos** no âmbito do **Ministério da Fazenda** e seus órgãos autônomos e entes tutelados.

■ 12.3.6.6. *Procuradoria-Geral Federal*

Em relação à representação judicial e extrajudicial das **autarquias**[55](#) e **fundações públicas federais**, foi instituída a **Procuradoria-Geral Federal**, que está **vinculada** à **Advocacia-Geral da União** (art. 9.º, *caput*, da Lei n. 10.480/2002 e arts. 2.º, § 3.º, e 17 da LC n. 73/93).

Com **autonomia administrativa** e **financeira**, aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas compete:

- exercer a sua representação judicial e extrajudicial;
- prestar as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos;
- promover a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

■ **12.3.6.7. Procuradoria-Geral do Banco Central**

No caso particular do *Banco Central do Brasil*, muito embora seja a instituição uma autarquia, houve regramento **específico** e previsão de **carreira própria** a ser organizada também por **ato normativo**.

Trata-se da **Procuradoria-Geral do Banco Central**, que faz parte da estrutura administrativa do *Banco Central do Brasil* e está em igual sentido **vinculada** à **Advocacia-Geral da União** (arts. 2.º, § 3.º, e 17 da LC n. 73/93). É responsável, com **exclusividade**, por sua assessoria jurídica e representação judicial e extrajudicial, nos termos do art. 4.º da Lei n. 9.650/98 (cf. arts. 164 e 192 da CF/88).

■ **12.3.6.8. A prerrogativa da intimação pessoal dos advogados públicos e a regra no CPC/2015**

As legislações específicas, de modo geral, estabelecem a prerrogativa da **intimação pessoal** dos advogados públicos:

- **art. 38 da LC n. 73/93**: “as intimações e notificações são feitas nas pessoas do **Advogado da União** ou do **Procurador da Fazenda Nacional** que officie nos respectivos autos”;
- **art. 17 da Lei n. 10.910/2004**: “nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de

Procurador Federal e de **Procurador do Banco Central do Brasil** serão intimados e notificados pessoalmente”;

■ **art. 25 da Lei n. 6.830/80**: “Na execução fiscal, qualquer intimação ao **representante judicial da Fazenda Pública** será feita pessoalmente”.

O **CPC/2015** incorporou a regra das legislações específicas, deixando claro a prerrogativa da intimação pessoal em seu art. 183, *caput* e § 1.º: “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da **intimação pessoal**”, que será feita “por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Essa norma deixa claro que a prerrogativa da intimação pessoal deverá ser observada **em todos os graus de jurisdição**, inclusive nos tribunais superiores.

■ **12.3.6.9. A obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n. 10.910/2004, aplica-se ao rito dos Juizados Especiais Federais?**

NÃO.

De fato, o art. 17 da Lei n. 10.910/2004 estabelece que, nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os **ocupantes dos cargos das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil** serão **intimados e notificados pessoalmente**.

Apesar dessa regra geral explícita, em situação concreta, o STF **afastou** a sua aplicação ao rito dos Juizados Especiais, sob pena de se violar a oralidade e a agilidade na solução dos conflitos (princípio da especialidade).

A decisão foi tomada, por maioria, no julgamento do **ARE 648.629** (j. 24.04.2013), no qual o INSS atacava decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro que considerou intempestiva a interposição de recurso específico.

A maioria dos Ministros reconheceu, portanto, a total validade do *Enunciado n. 39 das Turmas Recursais*, que traz a seguinte interpretação: “a

obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei 10.910/2004, **não é aplicável ao rito dos Juizados Especiais Federais**".

Na prática, contudo, devemos reconhecer que toda essa discussão está perdendo o seu sentido em razão do processo eletrônico.

■ **12.3.6.10. Advogados públicos no âmbito da Administração Federal gozam de 30 ou de 60 dias de férias?**

30 dias.

Antes da promulgação da CF/88, o art. 1.º da Lei n. 2.123/53 (*procuradores das autarquias federais*) e o art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.069/62 — apesar de vetado, mantido em razão da derrubada pelo parlamento (*demaís membros do Serviço Jurídico da União*), prescreviam as mesmas atribuições, impedimentos e prerrogativas (a primeira lei) e os mesmos vencimentos, gratificações e vantagens (a segunda lei) dos membros do MPU (a primeira), dos Procuradores da República (a segunda).

Assim, não havia dúvida, como os membros do MPU gozavam, e ainda gozam, de 60 dias de férias anuais, que os referidos advogados públicos também fizessem jus ao mesmo direito.

O art. 18 da Lei n. 9.527/97, contudo, de modo explícito, **revogou** os mencionados dispositivos normativos, sendo que o seu art. 5.º, *caput*, estabeleceu: “aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado, assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos **30 dias de férias anuais**, a partir do **período aquisitivo de 1997**”.

A tese que se sustentava era que as leis anteriores à Constituição teriam sido recepcionadas com o *status* de lei complementar e, assim, a mencionada lei ordinária não poderia ter revogado o direito às férias de 60 dias.

Esse tema foi enfrentado em dois momentos pelo STF, inicialmente pela 2.^a

Turma e depois pelo Plenário (recurso extraordinário com repercussão geral):

■ **RE 539.370** (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.11.2010, **2.^a T.**, *DJE* de 04.03.2011): a Corte, analisando a carreira da *Procuradoria da Fazenda Nacional*, entendeu que a **lei ordinária poderia ter revogado** referidos atos normativos anteriores à nova Constituição, na medida em que a exigência de lei complementar, prevista no art. 131, CF/88, foi direcionada apenas para *organização e funcionamento* da AGU, não alcançando os direitos e garantias dos advogados públicos a serem tratados como **regime jurídico dos servidores** que, no caso, são veiculados por lei ordinária, já que não exigida a lei complementar nos termos do art. 61, § 1.º, II, “c”. No mais, não há direito adquirido a regime jurídico, conforme tanto já manifestou a Corte — para se ter um exemplo, cf. RE 345.458;

■ **RE 602.381** (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.11.2014, Plenário, *DJE* de 04.02.2015): nesse outro precedente, agora analisado pelo **Pleno** do STF, a decisão se deu em relação à carreira dos *Procuradores Federais*. Em igual sentido, entendeu o STF que a lei ordinária teria validamente revogado os atos normativos editados antes do advento da nova Constituição, que os recepcionou com o *status* de lei ordinária, declarando, assim, o direito às férias de **30 dias**.

Em relação à carreira dos *Advogados da União*, muito embora o tema ainda não tenha sido enfrentado de modo específico pelo STF (pendente), também entendemos que deva ser reconhecido o direito de 30 dias, e não o de 60, a partir do advento do art. 5.º da Lei n. 9.527/97 que revogou o art. 1.º da Lei n. 2.123/53 e o art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.069/62, não recepcionados com natureza de lei complementar.

Lembramos que o art. 26 da LC n. 73/93 — *Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União* (que não se aplicou de imediato em razão da regra específica previstas nos dois diplomas produzidos antes de 1988), a partir da revogação expressa pela Lei n. 9.527/97, passou a dispor inteiramente sobre a matéria, sendo que, no caso, remete para a **Lei n. 8.112/90**, cujo art. 77 estabelece o prazo de **30 dias** de férias anuais, devendo ser pago ao servidor, conforme art. 76 da lei, por ocasião das férias e independentemente de solicitação, um

adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias (a lei, no fundo, reflete o direito assegurado nos arts. 39, §§ 3.º e 7.º, XVII, CF/88).

O mesmo entendimento deve ser feito para os *Procuradores do Banco Central*, especialmente por não ter a Lei n. 9.650/98 estabelecido regra distinta, aplicando, assim, a **regra geral para os servidores estatutários federais**, no caso, o citado art. 77 da Lei n. 8.112/90.

Apenas a título de informação, lembramos que **membros do Ministério Público e magistrados**, apesar da polêmica e discussão sobre a matéria, **ainda gozam de férias anuais de 60 dias** (art. 51, da Lei n. 8.625/93 — *LONMP*; art. 220, da LC n. 75/93 e art. 66 da LC n. 35/79 — *LOMAN*).

Não nos parece possam os referidos atos normativos ser declarados inconstitucionais sob o fundamento da isonomia em relação às carreiras da advocacia pública. Trata-se, em verdade, de política legislativa e que **depende de lei** para modificar o atual regime. A eventual insatisfação ao direito hoje assegurado aos membros do Ministério Público e aos magistrados deve ser discutida no **plano político**, e não judicial, dependente, necessariamente, insistimos, de **lei específica**.

Da mesma forma, o pedido de aumento de 30 para 60 dias pelos advogados públicos não pode ser deferido pelo Poder Judiciário, **nem mesmo à luz do princípio da isonomia**, pois, no caso, não cabe ao Poder Judiciário legislar sobre o assunto, sob pena de violar o princípio da separação de poderes (art. 37, X e XIII, da CF/88).

Aliás, entendemos que a tese jurídica materializada na S. 339 (editada em 13.12.1963), convertida na **SV 37**, pode ser aqui aplicada em relação à equiparação de direitos entre carreiras distintas: “não cabe ao Poder Judiciário, **que não tem função legislativa**, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (conversão em 16.10.2014). [56](#)

■ 12.3.7. Procuradoria-Geral dos Estados e do Distrito Federal

■ 12.3.7.1. *Estrutura unitária*

A **representação judicial** e a **consultoria jurídica** das respectivas unidades federadas serão exercidas pelos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em **carreira**, cujo ingresso dependerá de **concurso público de provas e títulos**, com a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil** em todas as suas fases (art. 132).

Dessa forma, a organização da Procuradoria deverá implementar-se dentro de uma **estrutura unitária**, cabendo, com **exclusividade**, aos Procuradores, formalmente constituídos e por concurso público, as atividades de **representação judicial** (salvo eventual impedimento de todos os procuradores) e **consultoria jurídica** (salvo a possibilidade de **eventual** contratação de **pareceres jurídicos** em caso específico e em razão de **notoriedade** de jurista na matéria).

A **única** exceção a essa regra no tocante à administração direta está contida no art. 69 do ADCT, que **permite** aos Estados manter **consultorias jurídicas separadas** de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, **desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções**.

A regra, contudo, é a exclusividade da representação e consultoria pelos Procuradores do Estado ou do DF.

Ao tratar do assunto, com precisão, o Min. Ayres Britto, partindo da análise dos arts. 131 e 132 da CF/88, observa que “a simples comparação entre os mencionados dispositivos revela que, no âmbito do **Poder Executivo**, as atividades de **consultoria** e **assessoramento jurídico** são **exclusivamente confiadas pela Constituição Federal aos procuradores de Estado**, com organização em **carreira** e **ingresso por concurso de provas e títulos**, exigida ainda a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Isso como condição de **qualificação técnica** e **independência funcional**. Independência e qualificação que hão de presidir a atuação de quem desenvolve as atividades de orientação e representação jurídica, tão necessárias ao regular

funcionamento do Poder Executivo. Tudo sob critérios de **absoluta técnica**, portanto, até porque tais atividades são constitucionalmente categorizadas como ‘funções essenciais à Justiça’ (Capítulo IV do Título IV da CF). Essa **exclusividade** dos procuradores de Estado para a **atividade de consultoria e representação jurídica**, entendidas aqui como assessoramento e procuratório judicial, é **incompatível com a natureza dos cargos em comissão**, que se definem como da estrita confiança da autoridade nomeante, matéria já devidamente examinada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1.557, da relatoria da ministra Ellen Gracie; 881-MC, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 1.679, da relatoria do ministro Gilmar Mendes”. [57](#)

Avançando e até destoando da decisão acima, a nosso ver nada impediria que o Estado, simetricamente à regra contida no art. 131, fizesse a previsão, por lei, de **procuradores autárquicos** e de **fundações públicas** em âmbito estadual ou no DF, para a representação judicial e extrajudicial das **autarquias** e **fundações públicas estaduais**, podendo ser considerados **vinculados** à Procuradoria do Estado, claro, sempre por concurso público.

Esse tema foi decidido pelo STF no **RE 558.258**, e nesse sentido posicionou-se a 1.^a Turma, acompanhando o voto do Min. Lewandowski (j. 09.11.2010, *DJE* de 18.03.2011).

CUIDADO: o tema precisa ser explicitado pelo Pleno do STF. No precedente anterior (ADI 4.261), o Pleno, nos termos do voto do Relator, havia percebido uma distinção entre a redação dada ao art. 131 e ao art. 132, não havendo, neste, a indicação de órgãos vinculados (**matéria pendente**).

Entendemos, contudo, e na linha do precedente da 1.^a Turma, razoável a criação da carreira de **advogados públicos** da **administração indireta estadual**, e isso decorreria de **opção política**, devendo estar vinculados à Procuradoria-Geral do Estado ou do DF.

Assim, em seu voto, o Min. Relator, aceitando a existência desses procuradores autárquicos, decidiu que não pode a lei local criar distinções remuneratórias. Ou seja, o art. 37, XI, ao fixar o subteto em 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, não distinguiu o “procurador”, que pode ser tanto o do

Estado como os *autárquicos* ou de *fundações públicas* (cf. Inf. 578/STF).

■ 12.3.7.2. Nomeação e destituição do Procurador-Geral pelo Governador

O **Procurador-Geral do Estado** é o chefe da carreira, não havendo, no entanto, previsão constitucional sobre o processo de sua **nomeação** e **destituição**.

O texto também não traz regras sobre o processo de nomeação e destituição do **Procurador-Geral do Distrito Federal**.

Daí o entendimento do STF de que ficou ao encargo do legislador local fixar os procedimentos nas Constituições Estaduais e na Lei Orgânica do DF, especialmente em razão da **autonomia federativa** e diante da capacidade de auto-organização.

Em razão da **simetria**, porém, determinou a Corte que as Constituições locais **não podem subtrair do Governador a prerrogativa de nomear e exonerar, livremente, o Procurador-Geral do Estado**. Trata-se, portanto, de **cargo de confiança**, ou seja, de **cargo em comissão**, podendo, pois, o Procurador-Geral ser **demitido *ad nutum***.

Apesar de haver entendimento anterior por parte da Suprema Corte no sentido de que a Constituição estadual poderia estabelecer que a escolha pelo Governador se desse *dentre membros da carreira* (não sendo essência do cargo em comissão a inexistência de qualquer limite — cf. **ADI 2.581**, j. 16.08.2007), o entendimento **modificado** e **atual** do STF é o de que **não pode haver como limitação o requisito de o advogado ser integrante da carreira da Procuradoria** para ser nomeado Procurador-Geral.

Assim, deve-se seguir simetricamente o procedimento para a escolha do AGU, regrado no art. 131, § 1.º, qual seja, trata-se de cargo de livre nomeação e destituição pelo Chefe do Executivo.

E não poderia, também, a Constituição Estadual, ou a Lei Orgânica do DF, prescrever que a destituição dependesse de prévia autorização do Legislativo local:

“EMENTA: (...) A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à autorização da Assembleia Legislativa, ofende o disposto no art. 84, XXV, e art. 131, § 1.º da CF/1988. Compete ao chefe do Executivo dispor sobre as matérias exclusivas de sua iniciativa, não podendo tal prerrogativa ser estendida ao Procurador-Geral do Estado (...). O cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, que pode escolher o Procurador-Geral entre membros da carreira ou não. Precedentes” (**ADI 291**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07.04.2010, Plenário, *DJE* de 10.09.2010).

■ 12.3.7.3. **Garantias e impedimentos dos Procuradores do Estado e do DF**

Conforme visto, a Constituição foi bastante tímida ao tecer as regras sobre os Procuradores dos Estados e do DF. Podemos esquematizar como segue:

■ **estabilidade:** aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 132, parágrafo único (*acrescentado pela EC n. 19/98*) é assegurada **estabilidade** (*e não vitaliciedade*) após **3 anos** (*e não 2 anos*) de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Lembrar que, antes da aludida alteração, a estabilidade dos Procuradores era atingida após **2 anos** de efetivo exercício. De maneira correta, o art. 28 da *EC n. 19/98* assegurou e manteve o prazo de 2 anos aos servidores que se encontravam em estágio probatório quando da promulgação da *EC n. 19*, sem prejuízo da avaliação especial de desempenho por comissão instituída para tal finalidade (art. 41, § 4.º);

■ **remuneração:** a Constituição assegura aos Procuradores de Estado e do DF a remuneração exclusivamente por **subsídio**, bem como a sua **irredutibilidade** (art. 135, c/c o art. 39, § 4.º, da CF/88). Nos termos do art. 37, XV, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI (qual seja, **subteto**, limitado a 90,25% do subsídio mensal de Ministro do STF) e XIV (do art. 37) e nos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;

■ **inamovibilidade?:** conforme decidiu o STF, “a garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição Federal *apenas* aos *Magistrados*, aos *membros do Ministério Público* e aos *membros da Defensoria Pública*, **não podendo ser estendida aos Procuradores do Estado**” (ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07.04.2010, Plenário, DJE de 10.09.2010);

■ **prerrogativa de foro:** de acordo com a Corte, o art. 125, § 1.º, CF/88, ao estabelecer que a competência dos tribunais estaduais será **definida** na Constituição do Estado, **convoca** o constituinte estadual para **demarcar** o âmbito da competência originária do tribunal local, desde que, naturalmente, sejam observados os princípios da CF. Dessa forma, a definição dessa competência não poderá ser genérica, indefinida, nem aberta, devendo ser clara, direta e específica. Assim, **a Constituição Estadual não poderá transferir para o legislador infraconstitucional a especificação das autoridades que serão originariamente julgadas pelo TJ** (ADI 3.140, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.05.2007, Plenário, DJ de 29.06.2007. No mesmo sentido: HC 103.803, Rel. Min. Teori Zavaski, j. 1.º.07.2014, Plenário, DJE de 06.10.2014). Diante do exposto, **desde que haja expressa previsão na Constituição estadual**, o STF tem reconhecido a prerrogativa de foro para os Procuradores de Estado e do DF;

■ **independência funcional?:** o STF **não** a aceitou no julgamento da **ADI 470** (j. 1.º.07.2002), entendendo ser inerente a outras categorias, como o Ministério Público. A decisão é anterior à nova composição e **poderia ser repensada** em uma tentativa de flexibilização. Em julgamento mais recente, na **ADI 4.261**, j. 02.08.2010, no voto do Min. Ayres Britto (*vide* passagem no *item 12.3.7.1*, acima), Relator, sustentou a ideia de independência funcional (**tema pendente de explicitação**);

■ **intimação pessoal:** de acordo com o art. 183, *caput* e § 1.º, CPC/2015, “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da **intimação pessoal**”, que será feita “por carga, remessa ou meio eletrônico”;

■ **exercício da advocacia fora das atribuições institucionais:** como não há previsão constitucional, a definição ficou ao encargo das Constituições Estaduais e da Lei Orgânica do DF. Não havendo proibição, poderão advogar. Assim, a análise deverá ser feita de acordo com cada regra estadual (dependendo da prova que forem enfrentar) e, no caso do DF, no *fechamento desta edição*, não havia proibição aos seus Procuradores, que, por consequência, podiam advogar, mas, é claro, desde que não contrariassem os interesses do DF.

■ 12.3.8. Procuradoria-Geral dos Municípios

Já mencionamos que não houve previsão explícita de *Procuradorias Municipais*, podendo, naturalmente e **desde que observadas as regras constitucionais**, a matéria ser tratada nas Constituições Estaduais, Leis Orgânicas e legislação própria.

André Ramos Tavares ensina que a *procuradoria municipal* “... não foi contemplada pela Constituição como instituição obrigatória (até rendendo-se à realidade de municípios que não teriam como arcar com um quadro de advogados públicos permanentes)”. [58](#)

Não há previsão constitucional proibindo ou permitindo os *Procuradores dos municípios* de advogar fora das atribuições institucionais. Assim, essa definição ficará ao encargo das Constituições Estaduais e das leis orgânicas. **Não havendo proibição, poderão advogar.**

■ 12.3.9. Advocacia pública e os honorários de sucumbência no CPC/2015

De acordo com o art. 85, § 19, do CPC/2015, “os **advogados públicos** perceberão honorários de sucumbência, **nos termos da lei**”.

Trata-se de tema bastante polêmico introduzido por emenda da Câmara dos Deputados e não afastado pelo Senado Federal e sobre o qual ainda estamos refletindo.

Conforme anotou Cassio Scarpinella Bueno, “para evitar a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo — remuneração de servidores públicos, aí incluídos advogados públicos, é tema que demandaria iniciativa legislativa do Chefe do Executivo Federal, Estadual e Municipal, consoante o caso (art. 61, § 1.º, II, ‘a’, da CF) — importa entender a previsão inócua. Inócua porque ela, na verdade, só pode ser compreendida no sentido literal da remissão que faz. Que há ou que haverá uma lei (federal, estadual ou municipal, consoante o caso) que trata do assunto, lei esta que não é — nem pode ser, sob pena de incidir no vício anunciado — o novo CPC”.[59](#)

■ 12.4. ADVOCACIA

O art. 133 da CF/88 dispõe que o **advogado [60](#)** é **indispensável à administração da justiça**, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Sobressaem, então, dois princípios: **a) indispensabilidade do advogado**, que não é, contudo, absoluto, por exemplo, na interposição do *habeas corpus*, que dispensa o advogado; na revisão criminal; nos denominados Juizados de “Pequenas Causas” (em âmbito estadual, nas causas com valor de até 20 salários mínimos — art. 9.º, *caput*, da Lei n. 9.099/95 e, conforme a Lei n. 10.259, de 12.07.2001, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, nas causas cíveis de até 60 salários mínimos, de acordo com a **possibilidade** de dispensa prevista no art. 10 da referida lei); na Justiça do Trabalho etc.;[61](#) **b) imunidade do advogado**, que também não é irrestrito, devendo obedecer aos limites **definidos na lei** (Estatuto da OAB — Lei n. 8.906/94) e restringir-se, como prerrogativa, às manifestações durante o exercício da atividade profissional de advogado.[62](#)

Requisitos para a inscrição na OAB, como advogado: **a)** capacidade civil; **b)** diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada; **c)** título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro; **d)** aprovação em Exame de Ordem; **e)** não exercer atividade

incompatível com a advocacia; **f)** idoneidade moral; e **g)** prestar compromisso perante o Conselho (cf. art. 8.º do Estatuto da OAB).

■ 12.5. ESTATUTO DA OAB À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF

O STF interpretou diversos dispositivos do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) no julgamento das ADIs 1.127, 1.105, 1.194, 2.522, 3.026, 3.168, 3.541; RE 603.583 e SVs 5 e 47. Passaremos a analisá-los.

■ 12.5.1. ADIs 1.105 e 1.127 [63](#)

■ 12.5.1.1. A exegese fixada pelo STF

■ Art. 1.º São atividades privativas de advocacia: I — a postulação a **qualquer** órgão do Poder Judiciário e **aos juizados especiais**.

A alegação de inconstitucionalidade da expressão “aos juizados especiais” foi julgada **prejudicada** tendo em vista a superveniência do art. 9.º da Lei n. 9.099/95, que permite que a parte demande sem advogado nas causas de até 20 salários mínimos.

Contudo, o STF julgou procedente o pedido para declarar a **inconstitucionalidade** da expressão “**qualquer**”, já que a presença dos advogados, como vimos, em certos atos, pode ser dispensada (ex.: juizados especiais, Justiça do Trabalho, impetração do *habeas corpus* e ações revisionais).

■ Art. 2.º O advogado é indispensável à administração da justiça. (...) § 3.º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta Lei.

O STF declarou **constitucional** a regra, com fundamento no art. 133 da CF/88, que também remete à lei (ao Estatuto) os limites da referida

inviolabilidade.

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) § 2.º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação **ou desacato** puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.

O STF declarou a **inconstitucionalidade** da expressão “**ou desacato**”. Ou seja, no exercício da profissão, **o advogado pode ser processado por desacato praticado contra funcionário público**. Segundo o STF, tal prerrogativa, ou seja, não responder, criminalmente, o advogado pela prática de desacato, criaria desigualdade entre o juiz e o advogado, retirando do juiz a autoridade indispensável à condução do processo. Veja, também, que o texto do referido § 2.º não menciona o crime de *calúnia*. Assim, o advogado também pode ser processado quando caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.

Nesse sentido, “a Turma indeferiu *habeas corpus* impetrado contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, que negara provimento a recurso interposto pelo ora paciente, no qual se pretendia a extinção do processo penal de conhecimento contra ele instaurado pela suposta prática do crime de desacato contra policial militar. Invocava-se, na espécie, a aplicação do § 2.º do art. 7.º da Lei n. 8.906/94 (...). Considerou-se o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 1.127/DF (...), no sentido da inconstitucionalidade da expressão ‘e desacato’ contida no aludido dispositivo. **HC 88.164/MG**, Rel. Min. Celso de Mello, 15.8.2006” (*Inf. 436/STF*). [64](#)

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) II — ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de **busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB** (redação **anterior** à Lei n. 11.767, de 07.08.2008 —

vide comentário abaixo).

O STF declarou, analisando a redação anterior à Lei n. 11.767/2008, **constitucional**, nos termos do art. 5.º, XII, da CF/88, seja a possibilidade de busca e apreensão em escritório de advocacia, seja a necessidade, nesta hipótese, de acompanhamento de representante da OAB. Naturalmente, se, após ser solicitada, expressamente e em caráter confidencial, a indicar o representante, não o fizer, poderá o Judiciário implementar a busca e apreensão sem que isso gere ilicitude da prova resultante da apreensão.

Cabe alertar que a **Lei n. 11.767/2008** alterou o inciso II do art. 7.º, que passou a ter a seguinte redação: “... a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia”.

Por sua vez, o art. 7.º, § 6.º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de **advogado**, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do *caput* do art. 7.º, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.

Tal ressalva, contudo, não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) IV — ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB.

O STF julgou **constitucional** a necessidade de representante da OAB para a

prisão em flagrante de advogado por motivo ligado ao exercício da advocacia. No entanto, os Ministros fizeram constar que a prisão em flagrante é válida se a OAB, devidamente comunicada, não encaminhar representante em tempo hábil e razoável.

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) V — não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, **assim reconhecidas pela OAB**, e, na sua falta, em prisão domiciliar.

O STF declarou a **inconstitucionalidade** da expressão “assim reconhecidas pela OAB”, já que, embora **firmado o direito** de ser recolhido preso em **sala de Estado-Maior**, 65 *antes de sentença transitada em julgado*, na prática quem deve reconhecer se as instalações e comodidades são condignas é o **Estado**, e não a OAB. Isso porque a administração de estabelecimentos prisionais constitui prerrogativa do Poder Público, e não da OAB.

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) IX — sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido.

O inciso foi declarado **inconstitucional** por violar o princípio do devido processo legal, assim como pelo fato de o contraditório ser estabelecido entre as partes, e não entre estas e o juiz.

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) § 3.º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo.

O STF julgou improcedente o pedido sobre esse ponto, entendendo **constitucional** a prerrogativa de só ser preso em flagrante, por motivo da profissão, nas hipóteses de crime inafiançável e tendo a necessidade de um representante da OAB para a lavratura do flagrante.

■ Art. 7.º São direitos do advogado: (...) § 4.º O Poder Judiciário e o Poder

Executivo devem instalar, em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso **e controle** assegurados à OAB.

O STF julgou parcialmente o pedido de inconstitucionalidade nesse ponto, entendendo **inconstitucional** a expressão “e controle”. Assim, é dever do Judiciário e do Executivo a instalação, em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, de salas especiais permanentes para os advogados; porém, o controle não será da OAB, e sim da Administração Pública, já que se trata de utilização de bem público.

■ Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: (...) II — membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta.

O STF julgou parcialmente procedente o pedido e, dando interpretação conforme a Constituição, excluiu da proibição do art. 28, II, do Estatuto da Advocacia os **juízes eleitorais** e seus **suplentes**, que poderão continuar advogando. Deve-se destacar que a afronta é em relação aos arts. 119, II, e 120, § 1.º, III. Assim, podem continuar advogando os juízes eleitorais e suplentes que forem advogados (tendo em vista que a Justiça Eleitoral tem uma composição mista). Isso porque a Justiça Eleitoral não os absorve de modo integral, nem lhes exige exclusividade.

■ Art. 50. Para os fins desta Lei, os Presidentes dos Conselhos da OAB e das Subseções podem **requisitar** cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da Administração Pública direta, indireta e fundacional.

O Plenário, dando interpretação conforme a Constituição e sem redução de texto, estabeleceu que a “requisição” de cópias deve ser motivada e compatível com as finalidades da lei. Além disso, a OAB deve responsabilizar-se pelos

custos e preservar sempre os documentos que estejam cobertos por sigilo.

Finalmente, e para facilitar a vida dos ilustres bacharéis que vão enfrentar o **Exame de Ordem**, observamos que o acórdão da **ADI 1.127**, depois de 4 anos do julgamento, foi publicado e, assim, chegou o momento de sedimentar a matéria:[66](#)

■ 12.5.1.2. Quadro-resumo

VAMOS DECORAR

- o advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser **dispensada** em certos atos jurisdicionais;
- a imunidade profissional é **indispensável** para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público;
- a **inviolabilidade** do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional;
- a presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da **inviolabilidade** da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma;
- a prisão do advogado em **sala do Estado-Maior** é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público;
- a administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do **Estado**;
- a sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, **afronta** o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes;

- a imunidade profissional do advogado **não** compreende o **desacato**, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional;
- o múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em **flagrante** e na hipótese de **crime inafiançável**;
- o controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da **Administração forense**;
- a incompatibilidade com o exercício da advocacia **não** alcança os **juízes eleitorais** e seus **suplentes**, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição;
- a requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser **motivada**, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo **sigilo**.

■ 12.5.1.3. Sala de Estado-Maior

Para iniciarmos uma análise mais detida sobre o assunto, devemos, novamente, ler o art. 7.º, V, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia): “são direitos do advogado: não ser recolhido preso, **antes de sentença transitada em julgado**, senão em **sala de Estado-Maior**, com instalações e comodidades condignas, *assim reconhecidas pela OAB*, e, **na sua falta**, em **prisão domiciliar**”.

Conforme vimos, no julgamento da **ADI 1.127**, o STF estabeleceu que o dever de certificar se *as instalações e comodidades da sala de Estado-Maior são condignas* é do **Estado**, e não da OAB, declarando, assim, a inconstitucionalidade da expressão “*assim reconhecidas pela OAB*”.

A leitura do texto parece não deixar qualquer dúvida em relação à regra da **prisão especial do advogado antes do trânsito em julgado da sentença**

penal condenatória (quando, então, depois do trânsito em julgado, não mais haverá a prerrogativa): ou a prisão se dará em sala de Estado-Maior ou a prisão será domiciliar. Não há outra alternativa pela “letra da lei”.

Isso posto, surge a *primeira pergunta*: **o que é sala de Estado-Maior?**

Não houve previsão normativa. O STF, contudo, em recorrente precedente, estabeleceu a seguinte definição:

“Por Estado-Maior se entende o grupo de oficiais que assessoram o Comandante de uma organização militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar); assim sendo, ‘sala de Estado-Maior’ é o **compartimento de qualquer unidade militar** que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções. A distinção que se deve fazer é que, enquanto uma ‘**cela**’ tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém — e, por isso, de regra, contém **grades** —, uma ‘**sala**’ apenas ocasionalmente é destinada para esse fim. De outro lado, deve o local oferecer ‘**instalações e comodidades condignas**’, ou seja, condições adequadas de **higiene e segurança**” (Rel 4.535, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07.05.2007, Plenário, DJ de 15.06.2007).

Em momento seguinte, o Min. Dias Toffoli, por sua vez, nos autos das **Rels 5.826 e 8.853** (que foram julgadas improcedentes — j. 18.03.2015), durante a instrução, solicitou informações sobre o tema ao **Ministro de Estado da Defesa**, que apresentou os seguintes **esclarecimentos** (transcritos no voto do Min. Toffoli):

■ **Conceito de sala de Estado-Maior:** “não existe, em nosso regimento, uma definição exata do que seja sala de Estado-Maior, contudo aglutinando os costumes da lide castrense e alicerçado na definição de Estado-Maior, ou seja ‘Estado-Maior — Órgão composto de pessoal militar qualificado, que tem por finalidade assessorar o comandante no exercício do comando’ — *glossário das Forças Armadas MD35-G-01* (4.^a Ed./2007), pode-se dizer que ‘**sala de Estado-Maior**’ é um **compartimento de qualquer unidade militar que possa ser utilizado pelo Estado-Maior para exercer suas funções**”;

■ **Como militares tratam a questão (ofícios pelos quais se solicitam locais com salas de Estado-Maior para receberem advogados presos**

preventivamente, tendo em vista o que reza o estatuto da classe)?: “no que tange a essa questão, informo que nas instalações militares não existem compartimentos que ofereçam ambientes adequados para o recebimento de pessoas com as qualificações citadas. Quando ocorre a prisão de oficial, o usual é a separação de uma sala, onde são colocados meios mínimos, para que o militar permaneça durante o cumprimento da sanção disciplinar”.

Estabelecido o conceito, lançamos uma *segunda pergunta*: **como tem sido a interpretação da Suprema Corte em relação à regra contida no Estatuto da Advocacia?**

Analisando a jurisprudência do STF, observamos que o tema tem recebido várias interpretações, inclusive no sentido da **não aplicação da citada literalidade do Estatuto da Advocacia**, que estabelece uma **regra** (*prisão em sala de Estado-Maior*) e uma única **alternativa** no caso de sua falta (*prisão domiciliar*).

Como observou a Min. Rosa Weber na apreciação de pedido de liminar na **Rcl 18.023** (j. 21.08.2014), excepcionando a literalidade do art. 7.º, V, da Lei n. 8.906/94, “não exclui a possibilidade de acomodação do acusado em cárcere separado dos demais presos, quando **não se afigurar recomendável a prisão domiciliar e não existir Sala de Estado-Maior** na localidade” (Rcl 15.755/GO, Rel. Min. Luiz Fux, *DJE* de 04.6.2013). No mesmo sentido: Rcl 15.815/PB, Rel. Min. Luiz Fux, *DJE* de 14.6.2013; Rcl 17.143/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJE* de 05.5.2014; e Rcl 17.635/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJE* de 05.5.2014).

E concluiu: “ademais, o recolhimento de advogado em Sala de Estado-Maior, até o trânsito em julgado da condenação, comporta **interpretação**. Já se entendeu que o recolhimento em sala, com ou sem grades, na **Polícia Militar** atendia ao requerido (v.g.: HC 99.439 e Reclamação 5.192), e até mesmo que o recolhimento em **cela individual em ala reservada de presídio federal se mostrava hábil a tanto** (Reclamação 4.733). Na esteira da Reclamação 6.387, penso que o essencial é que o local ofereça **instalações e comodidades condignas** (Reclamação 4.535 e 6.387), por certo consideradas as limitações decorrente da prisão do agente, como na hipótese”.

Ainda sobre o tema, mas de modo mais amplo, em outro julgado, o Min. Gilmar Mendes sustentou que a regra contida no art. 7.º, V, do Estatuto da Advocacia teria sido **revogada** pela **Lei n. 10.258/2001** que, ao alterar o art. 295 do CPP, definiu em seus parágrafos que a prisão especial poderá se dar em cela distinta do mesmo estabelecimento prisional (**tese essa acolhida pela 2.ª T, STF, no julgamento da Rcl 14.267**, j. 05.08.2014, *DJE* de 30.10.2014).

O grande problema desse entendimento firmado pela 2.ª T., STF, é que ele viola a posição firmada pelo Plenário da Corte no julgamento de questão de ordem na ADI 1.127, que afastou a referida tese da revogação, vencidos apenas os Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso (j. 17.05.2006). Por esse motivo, entendemos que essa sugerida nova interpretação — revogação ou não da prerrogativa exclusiva do advogado pela Lei n. 10.258/2001 — deveria ter sido afetada ao Plenário para que, então, pudesse, na nova composição, reanalisar a matéria (*pendente nova apreciação pelo Pleno*).

Em nosso entendimento, essa flexibilização que vem sendo dada à literalidade da regra contida no Estatuto da OAB **extrapola** os limites da lei.

Concordamos que a *prisão domiciliar* pode não ser conveniente em situações concretas de envolvimento do advogado na prática de crimes. Contudo, a solução deveria ser no sentido de obrigar o Estado a ter as referidas salas de Estado-Maior, e **não**, de modo mais simplório, reservar uma cela especial para o advogado, muitas vezes, em presídios normais.

Em nossa opinião, muito embora o próprio *Estatuto da Advocacia* preveja a igualdade de tratamento entre magistrados e advogados, e àqueles se aplica a regra do CPP (art. 295, VI), parece ter sido estabelecido pelo legislador uma prerrogativa especial exclusiva do advogado e que, na prática, não tem sido observada nos precedentes citados.

Nessa linha, além dos casos já destacados, lembramos que, em outros julgados, não tão desproporcionais como a violação da literalidade do art. 7.º, V, da Lei n. 8.906/94, alguns Ministros estão afirmando que a expressão é **anacrônica** e que não haveria mais, fisicamente, sala de Estado-Maior no Brasil, bastando, conforme Ayres Britto, a existência de uma “... sala **em unidade**

castrense, com condições condignas de comodidade” (cf. Rcls 5.826 e 8.853, voto proferido em 19.08.2010). [67](#)

■ 12.5.2. ADIs 1.194, 2.522, 3.026, 3.168 e 3.541

■ Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando visados por advogados — ADI 1.194

Segundo o STF, “... referida norma visa à proteção e segurança dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, salvaguardando-os de eventuais prejuízos decorrentes de irregularidades cometidas por profissionais estranhos ao exercício da advocacia, além de minimizar a possibilidade de enganos ou fraudes” (*Inf. 445*).

■ Honorários de advogado empregado — disponibilidade — ADI 1.194

Ao analisar o art. 21, *caput*, e parágrafo único, da Lei n. 8.906/94, o STF entendeu “... ser possível haver estipulação em contrário entre a parte e o seu patrono quanto aos honorários de sucumbência, haja vista tratar-se de direito disponível” (*Infs. 445 e 547/STF*).

■ O advogado não está obrigado a pagar contribuição sindical — ADI 2.522

O art. 47 do Estatuto da OAB, Lei n. 8.906/94, estabelece que o pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical.

O STF entendeu **constitucional** a regra: “... Afastou-se a alegação de afronta aos artigos 149 e 150, § 6.º, da CF, ao fundamento de que o dispositivo impugnado foi devidamente veiculado por lei federal, e por se reputar a isenção concedida adequada, e não oportunista, desvinculada da matéria regulada pela lei. De igual modo, rejeitou-se a apontada violação ao princípio da igualdade, por não haver como estabelecer relação de igualdade entre os sindicatos de

advogados e os demais no que se refere à regular obtenção da receita oriunda da contribuição sindical, tendo em conta que o art. 44, II, da lei impugnada atribui à OAB a função tradicionalmente desempenhada pelos sindicatos, qual seja a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com a ressalva de que a defesa promovida pela Ordem alcança todos os inscritos e não apenas os empregados. Repeliu-se ainda a apontada ofensa ao art. 8.º, IV, da CF, uma vez que a contribuição nela prevista não se reveste de compulsoriedade. Também não se acolheu a tese de violação à independência sindical e ao princípio da liberdade de associação, já que o preceito impugnado não é expressivo de interferência e/ou intervenção na organização dos sindicatos, nem obsta a liberdade dos advogados. Por fim, considerou-se improcedente a assertiva de que o dispositivo hostilizado retiraria do sindicato a fonte essencial de custeio, haja vista a existência de muitas outras receitas dos sindicatos” (ADI 2.522/DF, Rel. Min. Eros Grau, 08.06.2006 — *Inf. 430/STF*).

■ Os funcionários da OAB não têm de prestar concurso público — ADI 3.026

O art. 79 do Estatuto determina a aplicação do **regime trabalhista** aos servidores da OAB. Nesse sentido, o STF entendeu ser dispensável a regra do concurso público para os funcionários da OAB, já que esta não integra a Administração Pública.

■ É constitucional a indenização do art. 79, § 1.º, do Estatuto — ADI 3.026

O Estatuto da OAB, em seu art. 79, § 1.º, concedeu aos servidores da OAB sujeitos ao regime da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias a partir da vigência da lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração.

Aqueles que não optassem pelo regime trabalhista, nos termos do art. 79, § 2.º, do Estatuto, seriam posicionados no **quadro em extinção**, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior.

O STF entendeu que “... a previsão de indenização seria razoável porque destinada a compensar, aos optantes pelo regime celetista, a perda de eventuais direitos e vantagens até então integrados ao patrimônio dos funcionários, e que o dispositivo estatuiu disciplina proporcional e consoante os princípios da igualdade e isonomia. Além disso, o preceito já teria produzido efeitos, devendo ser preservadas as situações constituídas por questões de segurança jurídica e boa-fé” (*Inf. 430/STF*).

■ **É constitucional a regra do art. 10 da Lei n. 10.259/2001 (Lei dos Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais), que dispensa a presença do advogado nos processos cíveis — ADI 3.168**

O art. 10 da Lei n. 10.259/2001 (Lei dos Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais) estabelece que as partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não.

O STF entendeu **constitucional** a regra, “... seja porque se trata de exceção à indispensabilidade de advogado legitimamente estabelecida em lei, seja porque o dispositivo visa ampliar o acesso à justiça”. Essa regra, todavia, vale só para os **processos cíveis**, já que, “... no que respeita aos processos criminais, considerou-se que, em homenagem ao princípio da ampla defesa, seria imperativo o comparecimento do réu ao processo devidamente acompanhado de profissional habilitado a oferecer-lhe **defesa técnica** de qualidade — advogado inscrito nos quadros da OAB ou defensor público”.

Ainda, o entendimento pela possibilidade de se dispensar advogado deve restringir-se ao processo cível, pois, por outro argumento, deve-se observar o art. 68 da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária (art. 1.º da Lei n. 10.259/2001), “... que determina a imprescindibilidade da presença de advogado nas causas criminais” (*Inf. 430/STF*).

■ **Advocacia e atividade policial — ADI 3.541**

A Constituição estabelece ser incompatível a advocacia, mesmo em causa própria, com as atividades ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a **atividade policial de qualquer natureza** (art. 28, V, da Lei n.

8.906/94).

O STF entendeu como **constitucional** essa regra: “a vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham, direta ou indiretamente, serviço de caráter policial, prevista no art. 28, V, da Lei 8.906/1994, não se presta para fazer qualquer distinção qualificativa entre a **atividade policial** e a **advocacia**. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer **cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo** das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial ao cumprimento das respectivas funções. Referido óbice não é inovação trazida pela Lei 8.906/1994, pois já constava expressamente no anterior Estatuto da OAB, Lei n. 4.215/1963 (art. 84, XII). Elegeu-se critério de diferenciação compatível com o princípio constitucional da isonomia, ante as peculiaridades inerentes ao exercício da profissão de advogado e das atividades policiais de qualquer natureza” (**ADI 3.541**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.02.2014, Plenário, *DJE* de 24.03.2014).

■ 12.5.3. Constitucionalidade do Exame de Ordem: vitória para os bacharéis em direito e conquista da sociedade

Como se sabe, o art. 8.º, IV, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) exige a **aprovação em Exame de Ordem** para **inscrição** como **advogado**.

A “OAB”, por sua vez, além de “controlar” a inscrição como advogado do bacharel em direito, participa dos concursos públicos para o ingresso na magistratura, no MP, nas procuradorias dos Estados e do DF, podendo, ainda, ajuizar a ADI e outras ações constitucionais, indicar membros e participar do CNJ, bem como do CNMP.

Diante dessa exigência, muitos bacharéis em direito começaram a se insurgir, e alguns conseguiram decisões judiciais favoráveis, afastando a exigência do *Exame de Ordem*, sob o fundamento dos *princípios da dignidade da pessoa humana*, da *igualdade* e do *livre-exercício de qualquer ofício, trabalho ou*

profissão (art. 5.º, XIII).

Em **14.12.2009**, os Ministros do STF decidiram haver repercussão geral no **RE 603.583**, que questionava a obrigatoriedade do Exame da OAB para que bacharéis em Direito pudessem exercer a advocacia.

Conforme se observa no site do STF, basicamente, o recorrente alegava, em referido RE, “... ofensa aos artigos 1.º, II, III e IV; 3.º, I, II, III e IV; 5.º, II e XIII; 84, IV; 170; 193; 205; 207; 209, II; e 214, IV e V, da Constituição Federal. Inicialmente, afirmava não haver pronunciamento do STF quanto à constitucionalidade do *Exame de Ordem*. Sustentava, em síntese: 1) caber apenas às instituições de ensino superior certificar se o bacharel é apto para exercer as profissões da área jurídica; 2) que a sujeição dos bacharéis ao referido exame viola o direito à vida e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, do livre-exercício das profissões, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem assim que representa censura prévia ao exercício profissional”.

Em **26.10.2011**, contudo, o STF, por unanimidade, julgou **constitucional** referida exigência.

Nos termos da linha de argumentação, o PGR declarou que “a liberdade profissional não confere um direito subjetivo ao efetivo exercício de determinada profissão, podendo a lei exigir qualificações e impor condições para o exercício profissional”, ressaltou. De acordo com o Procurador-Geral, ‘no caso da advocacia, diante da **essencialidade da atividade do advogado para a própria prestação jurisdicional**, parece muito consistente a opção do Poder Legislativo no sentido de estabelecer a aprovação do *Exame de Ordem* como condição para o exercício profissional’” (*Notícias STF*, 26.10.2011).

Assim, parece razoável, segundo o STF, o preenchimento da referida exigência normativa, até porque, nos termos do **art. 22, XVI**, compete privativamente à União legislar sobre **as condições para o exercício das profissões**.

Dessa forma, temos de reconhecer que o *Exame de Ordem* surge como um verdadeiro “concurso”, nos mesmos moldes e **dificuldades** dos concursos

públicos em geral e prestados pelos bacharéis em direito.

Por mais que pareça estranho dizer, diante da opção política do legislador que entendeu necessário o *Exame de Ordem*, não há dúvida de que referida decisão do STF caracteriza-se como **vitória para os bacharéis em direito**, além, é claro, de uma **conquista da sociedade**.

Isso porque a formação do estudante de Direito terá de ser extremamente séria, devendo o aluno se preparar durante os 5 anos de sua graduação.

Indiscutivelmente, as universidades passarão a ser mais cobradas e deverão entregar um **serviço de melhor qualidade, adequado e suficiente** para que o exame seja enfrentado e superado.

As faculdades que não conseguirem aprovar terão de rever as suas metodologias e aprimorar a formação dos seus alunos.

A decisão do STF, sem dúvida e insistimos, pode ser definida como inegável vitória dos bacharéis em Direito, que deverão receber um ensino adequado e suficiente para o exercício, com autonomia e segurança, da nobre função de advogado, **indispensável para a administração da justiça** (art. 133 da CF/88).

Parece, ainda, razoável a ponderação do Min. Fux no sentido de **aperfeiçoamento do Exame**, abrindo-o para outros segmentos da sociedade, até porque os concursos em geral têm a participação de outros órgãos ou entidades que exercem importante fiscalização.

Nessa linha, bem-vinda a proposta do **PL 1.284/2011-CD**, que determina a **obrigatoriedade de participação ativa de representantes do Ministério Público Federal e Estadual, da Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal e de representantes de entidade representativa de bacharéis** em todas as fases de elaboração, aplicação e correção das provas do *Exame de Ordem* da Ordem dos Advogados do Brasil.

Bacharéis comemorem... A **advocacia** acaba de ser **valorizada...**

■ 12.5.4. Súmula Vinculante 5/STF x Súmula 343/STJ

Vamos analisar, inicialmente, a redação de cada uma das súmulas que, como

se verá, estão em **contradição**, devendo, naturalmente, prevalecer o entendimento firmado na **SV 5/STF**:

SÚMULA VINCULANTE 5/STF	SÚMULA 343/STJ
■ A falta de defesa técnica por advogado no <i>processo administrativo disciplinar</i> não ofende a Constituição ■ Aprovação: Sessão Plenária de 07.05.2008	■ É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do <i>processo administrativo disciplinar</i> ■ Julgamento: 3.^a Seção, em 12.09.2007

O que o STF firmou não é que a **falta de defesa** não ofende a Constituição, mas que a falta de defesa **técnica**, por **advogado**, não ofende a Constituição, no **processo administrativo disciplinar**.

Dessa forma, fica a critério do servidor, no processo administrativo, contratar ou não advogado para a sua defesa.

Em nossa opinião — o STJ, até o *fechamento* desta edição, ainda não havia formalmente cancelado a referida S. 343 —, a interpretação estabelecida pelo STJ está **superada**, devendo prevalecer o entendimento firmado pelo STF na SV 5.

■ 12.5.5. Súmula Vinculante 47/2015

Conforme vimos ao tratar sobre o tema “precatórios” (*item 11.12*), o STF estabeleceu que a definição, prevista na Constituição Federal, de crédito de natureza alimentícia **não é exaustiva** (RE 470.407, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006, 1.^a T.).

Como exemplo, destacamos o art. 85, § 14, do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015) ao prescrever que os **honorários** constituem **direito do**

advogado e têm **natureza alimentar**, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Esse entendimento está consagrado na **SV 47** (DJE de 02.06.2015), nos seguintes termos: “os **honorários advocatícios** incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de **natureza alimentar** cuja satisfação ocorrerá com a **expedição de precatório** ou **requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza**”.

■ 12.6. DEFENSORIA PÚBLICA⁶⁸

■ 12.6.1. “Ondas renovatórias”

Cappelletti e Garth produziram interessante ensaio para o Projeto de Florença, buscando “... delinear o surgimento e desenvolvimento de uma abordagem nova e compreensiva dos problemas” de acesso à “ordem jurídica justa” (Kazuo Watanabe).⁶⁹

No referido estudo, os autores observam que o processo evolutivo dos instrumentos destacados para solucionar a problemática do acesso efetivo à justiça, nos países do Ocidente, está sedimentado em **3 grandes ondas renovatórias**, cada qual, do seu modo, tentando solucionar a problemática de acesso à ordem jurídica justa.

Conforme os autores, *e retomaremos a análise no item 14.10.21* deste estudo, a **primeira grande onda** teve início em 1965, concentrando-se na assistência judiciária. A **segunda** referia-se às “... reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses ‘difusos’, especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor”. O **terceiro movimento** ou **onda** foi pelos autores chamado de “enfoque de acesso à justiça”, reproduzindo e buscando as experiências anteriores, mas indo além, tentando “... atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo”.⁷⁰

Podemos afirmar, portanto, que o estudo da **defensoria pública e da garantia constitucional da assistência jurídica integral e gratuita** encontra fundamento na perspectiva da **primeira onda renovatória** de Cappelletti e Garth.

■ 12.6.2. Assistência jurídica integral e gratuita — aspectos gerais e evolução constitucional

O art. 5.º, LXXIV, da CF/88 dispõe que o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Esse direito e garantia fundamental instrumentaliza-se por meio da **Defensoria Pública**, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, nos termos do art. 134, *caput*, da CF/88.

No Brasil, a **assistência judiciária** só adquiriu *status* de **garantia constitucional** expressa a partir do advento da Constituição de 1934, art. 113, n. 32, com a seguinte redação: “a União e os Estados concederão aos necessitados *assistência judiciária*, criando, para esse efeito, órgãos especiais, e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”.

Tal **direito e garantia individual** foi, porém, retirado do texto de 1937, reaparecendo na Constituição de 1946, em seu art. 141, § 35: “o poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá *assistência judiciária* aos necessitados”, bem como na de 1967 (art. 150, § 32) e na EC n. 1/69 (art. 153, § 32): “será concedida *assistência judiciária* aos necessitados, na forma da lei”.

Finalmente, a regra é aprimorada pelo inciso LXXIV do art. 5.º da CF/88.

Confrontando os textos, percebe-se uma clara e importante distinção terminológica entre a **assistência judiciária** prevista nas Constituições de 1934, 1946, 1967 e EC n. 1/69 e a atual prescrição, esta muito mais ampla, da garantia de **assistência jurídica integral e gratuita**.

De acordo com a observação de Barbosa Moreira, “a grande novidade trazida pela Carta de 1988 consiste em que, para ambas as ordens de providências, o

campo de atuação já não se delimita em função do atributo ‘judiciário’, mas passa a compreender tudo que seja ‘jurídico’. A mudança do adjetivo qualificador da ‘assistência’, reforçada pelo acréscimo ‘integral’, importa notável ampliação do universo que se quer cobrir. Os necessitados fazem jus agora à dispensa de pagamentos e à prestação de serviços não apenas na esfera *judicial*, mas em todo o campo dos atos jurídicos. Incluem-se também na franquia: a instauração e movimentação de processos administrativos, perante quaisquer órgãos públicos, em todos os níveis; os atos notariais e quaisquer outros de natureza jurídica, praticados extrajudicialmente; a prestação de serviços de consultoria, ou seja, de informação e aconselhamento em assuntos jurídicos”.⁷¹

■ 12.6.3. Regras gerais

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente (**competência concorrente**) sobre *assistência jurídica e defensoria pública* (art. 24, XIII). Isso significa que a **União** legislará sobre **normas gerais** e os **Estados**, bem como o **Distrito Federal**, sobre regras **específicas**.

Nos termos do art. 134, § 1.º (antigo parágrafo único renumerado pela **EC n. 45/2004**), **lei complementar** organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais (art. 24, XIII) para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

Por seu turno, o art. 61, § 1.º, II, “d”, da CF/88 prevê serem de **iniciativa exclusiva do Presidente da República** (portanto indelegáveis) as leis que disponham sobre a organização da Defensoria Pública da União, bem como **normas gerais** para a organização da Defensoria Pública dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Territórios**.

O art. 48, IX, determina que o Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, disporá sobre a organização **administrativa** e

judiciária da Defensoria Pública da **União** e dos **Territórios** (redação dada pela **EC n. 69/2012**).

Não podemos nos esquecer dos arts. 21, XIII, e 22, XVII, ambos também com a redação dada pela **EC n. 69/2012**, que transferiu da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a sua Defensoria Pública.

A **EC n. 74/2013** explicitou a autonomia da Defensoria Pública do DF (que já havia sido estabelecida no art. 2.º da **EC n. 69/2012**) e, inovando, assegurou a autonomia para a Defensoria Pública da União.

Por sua vez, a **EC n. 80/2014** alterou drasticamente as regras sobre a Defensoria Pública elevando-a, como se verá melhor a seguir (cf. *item 12.6.6*), à condição de carreira totalmente desvinculada das demais indicadas na Constituição como *funções essenciais à Justiça*.

Destacamos, ainda, a **LC n. 80/94** (alterada pela LC n. 98/99 e pela LC n. 132/2009), [72](#) que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, prescrevendo normas gerais para a sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. [73](#)

A teor do art. 2.º da referida LC, a Defensoria Pública abrange, procurando harmonizar-se [74](#) com as novidades introduzidas pela **EC n. 69/2012** (que transferiu da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal):

- Defensoria Pública da União;
- Defensoria Pública dos Territórios;
- Defensoria Pública dos Estados;
- Defensoria Pública do Distrito Federal.

O art. 14 da LC n. 80/94 estabelece que a Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, junto às Justiças Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União.

Assim, percebe-se que nos Estados teremos tanto a Defensoria Pública da União (restringindo a sua atuação nos graus e instâncias administrativas federais) como a dos Estados. No âmbito do Distrito Federal, também a Defensoria Pública da União e a do Distrito Federal, organizada e mantida pelo próprio DF, bem como, nos Territórios, a da União, além da dos Territórios (quando criados), organizada e mantida, contudo, neste último caso, pela União (EC n. 69/2012, arts. 21, XIII, e 22, XVII).

■ 12.6.4. O fortalecimento da Defensoria Pública pela EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário), bem como pelas ECs ns. 69/2012 e 74/2013

A **EC n. 45/2004** fortaleceu as Defensorias Públicas Estaduais ao constitucionalizar a autonomia funcional e administrativa e fixar competência para proposta orçamentária, nos termos do § 2.º, inserido no art. 134: “às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2.º”.

O então Senador Bernardo Cabral, primeiro relator da Reforma, em seu parecer observou que “a atribuição da autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas, e o poder de iniciativa de sua proposta orçamentária, conferirá a essas instituições uma importante desvinculação do Poder Executivo, com o qual não guardam qualquer relação de afinidade institucional, além de propiciar um fortalecimento da instituição e da consequente atuação institucional”.

Referida autonomia financeira é consolidada pela nova regra do art. 168 da CF/88, [75](#) na medida em que, conforme também observou Bernardo Cabral, passa a existir “... previsão de repasse direto do duodécimo orçamentário até o dia 20 de cada mês. A negativa desse repasse configura descumprimento de ordem constitucional e, portanto, crime de responsabilidade, pela letra do art. 85 da Constituição Federal”.

O constituinte reformador se “esqueceu”, contudo, de fixar as referidas regras para as **Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal**. Essa situação seria corrigida pela “PEC Paralela da Reforma do Poder Judiciário”, que, “atrasada”, ainda tramita.

A **EC n. 69/2012**, por sua vez, com atraso de quase 8 anos (já que o assunto deveria ter sido introduzido pela *Reforma do Judiciário*), finalmente, transferiu, agora formal e oficialmente, da União para o Distrito Federal, as atribuições de **organizar** e **manter** a Defensoria Pública do DF.

Anteriormente, segundo o art. 21, XIII, em sua redação original, a Defensoria Pública do DF seria organizada e mantida pela União, assim como ainda acontece com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar (art. 21, XIV).

No tocante à Defensoria Pública do DF, todavia, essa situação **nunca** se observou. Ou seja, a União, até o advento da EC n. 69/2012, não tinha, ainda, criado a Defensoria Pública do DF.

Na prática, o serviço de assistência judiciária era exemplarmente prestado pelo **Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal (CEAJUR-DF)**, criado, em 1987, pelo Governo do Distrito Federal.

Dessa forma, a EC n. 69/2012 corrige a distorção de manter o órgão de assistência sob a organização da União para adequar-se à situação prática que já se observava e, assim, fortalecer a Defensoria Pública do DF.

Nesse sentido, o art. 2.º da EC n. 69/2012 estatui que, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, **aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal** os mesmos **princípios** e **regras** que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.

Portanto, também à Defensoria Pública do Distrito Federal são asseguradas **autonomia funcional** e **administrativa** e a **iniciativa de sua proposta orçamentária** dentro dos limites previstos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2.º.

Toda essa evolução está consagrada na **EC n. 74/2013**, que acrescenta o § 3.º ao art. 134, para deixar claro que às **Defensorias Públicas da União** e do

Distrito Federal aplica-se o disposto no art. 134, § 2.º, ou seja, a já citada autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de proposta orçamentária, inicialmente asseguradas para a Defensoria Pública Estadual.

Pois bem, diante do incontestável reconhecimento de **autonomia funcional, administrativa e financeira da defensoria pública estadual, do DF e da União** (ECs ns. 45/2004, 69/2012 e 74/2013), não se admite a sua vinculação a quaisquer dos Poderes. Assim, estabelecer que a defensoria pública é integrante do Poder Executivo, ou subordinada ao Governador de Estado, ou integrante de determinada Secretaria do governo, tudo isso **afronta a Constituição**. Vejamos:

“EMENTA: A EC 45/2004 outorgou expressamente autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2.º): donde, ser inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de Estado. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2.º, da CF pela EC 45/2004 é de **eficácia plena e aplicabilidade imediata**, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos” (ADI 3.569, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007. No mesmo sentido: ADI 4.056, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2012, Plenário; ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2012, Plenário).

■ 12.6.5. Autonomia da Defensoria Pública da União — DPU. Constitucionalidade da EC n. 74/2013. A pretensão formulada na ADI 5.296 (10.04.2015) mostra-se totalmente infundada

Conforme já pudemos observar, a EC n. 45/2004 (*Reforma do Poder Judiciário*) estabeleceu as autonomias funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias apenas em relação às **Defensorias Públicas Estaduais**.

Inegavelmente, dado o **caráter nacional e uno da instituição**, organizada em cada ente federativo à luz da **simetria**, bem como a necessidade de se estabelecer um tratamento **isonômico** entre as defensorias nos âmbitos federal, estadual e distrital, houve um grave erro cometido pelo constituinte reformador

ao tratar, na EC n. 45/2004, apenas da Defensoria Pública Estadual.

Na busca de sua correção, algumas medidas foram implementadas: a) nova proposta de emenda durante a votação da *Reforma do Judiciário*, corrigindo a imperfeição; b) ajuizamento da ADI 4.282 (pela *Associação Nacional dos Defensores Públicos da União — ANDPU*), com o pedido de interpretação conforme a Constituição para se reconhecer a autonomia da Defensoria como um todo, e não apenas a estadual; c) em momento seguinte, de modo mais efetivo, a aprovação de emendas constitucionais.

Como se sabe, e na ordem apresentada, a primeira tentativa de correção do “erro” foi a apresentação, pelo Senado Federal, da **PEC 29-A**, já aprovada naquela Casa e que, ainda, tramita na Câmara dos Deputados desde o ano de 2005 (como **PEC 358**), conhecida como *PEC Paralela da Reforma do Poder Judiciário* e que fixa, de modo natural e correto, a autonomia para as Defensorias Públicas do DF e da União.

Diante da brutal demora em se aprovar o texto, bem como da inexistência de julgamento da citada ADI 4.282, novas propostas de emendas à Constituição, tratando o tema de modo isolado, foram aprovadas, destacando-se a **EC n. 69/2012**, que deu autonomia para a Defensoria Pública do DF e a **EC n. 74/2013**, que fixou, em igual amplitude, autonomia para a Defensoria Pública da União.

Inusitadamente, no dia **10 de abril de 2015**, portanto quase 2 anos após a promulgação da **EC n. 74/2013** (que se deu em 06.08.2013), e com infundado pedido de liminar, a Presidente da República, Dilma Rousseff, ajuizou a **ADI 5.296**, requerendo fosse declarada a inconstitucionalidade da emenda, com fundamento em dois esdrúxulos argumentos: a) vício formal por suposta violação à regra da iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, II, “c” — iniciativa para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União); b) por consequência, violação à cláusula pétrea da separação de poderes (art. 60, § 4.º, III).

Inegavelmente, com o máximo respeito, **os argumentos são totalmente insustentáveis.**

Em primeiro lugar, conforme já tivemos a oportunidade de estabelecer ao analisar a EC n. 73/2013, que criou os Tribunais Regionais Federais das 6.^a, 7.^a, 8.^a e 9.^a Regiões, introduzindo o § 11 ao art. 27 do ADCT (*item 9.13.3.3.3*), em discussão na ADI 5.017 (pendente), não se pode fazer qualquer relação entre o princípio da simetria a ser observado nos âmbitos estadual, distrital e municipal, com a manifestação do poder constituinte derivado reformador a alterar a Constituição Federal.

As matérias de **iniciativa reservada** estabelecidas para o Presidente da República, por simetria, devem ser observadas pelos demais Chefes do Poder Executivo, mas não em relação ao processo de reforma da Constituição da República.

De fato, conforme consolidou o STF, para esses temas previstos no art. 61, § 1.º, II, nem mesmo a emenda à Constituição **Estadual** poderia servir como mecanismo para “driblar” a previsão da iniciativa reservada ao Governador de Estado (nesse sentido, cf. o voto do Min. Marco Aurélio na ADI 3.930).

Também pudemos expor que essa regra veio a ser flexibilizada pelo STF no sentido de não haver a exigência de se observar a regra da iniciativa reservada quando estivermos diante da manifestação do **poder constituinte derivado decorrente inicial**, ou seja, aquele que elabora a Constituição do Estado ou a Lei Orgânica do DF **pela primeira vez** (cf. **ADI 2.581**, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, j. 16.08.2007, Plenário, *DJE* de 15.08.2008. No mesmo sentido: **ADI 1.167**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.11.2014, Plenário, *DJE* de 10.02.2015 — cf. *item 9.13.3.3.10*).

Dessa forma, o STF apenas enfrentou a questão envolvendo a legislação estadual (e, em outros julgados, legislações municipais) e as emendas introduzidas no plano estadual para a alteração da Constituição estadual (nesse sentido, todos os precedentes citados na ADI 5.296, a saber: ADIs 3.930, 2.966, 1.381, 3.295, 4.154, 2.420 e 637).

O dever de se observar simetricamente as regras estabelecidas no art. 61, § 1.º, II, decorre da disposição contida no art. 25, *caput*, ao prever que os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, **observados**

os princípios da Constituição Federal (no mesmo sentido, no âmbito do Distrito Federal, conforme art. 32, § 3.º, bem como para os Municípios, em razão do art. 29, *caput*).

Assim, no momento do ajuizamento da referida ADI 5.296 (10.04.2015), não havia qualquer precedente da Corte que tivesse reconhecido o sugerido *vício formal subjetivo de inconstitucionalidade* para as hipóteses de emendas à Constituição Federal que veiculam matérias de iniciativa reservada ao Presidente da República. Aliás, a pretensão formulada, inegavelmente, está **destituída de fundamento**, mostra-se **infundada, viola a regra expressa do art. 60, I, da CF/88**, além de **alterar a verdade dos fatos**, no caso, como se disse, a **jurisprudência do STF** que, ao contrário do afirmado na petição inicial, **não tem qualquer relação com a hipótese da EC n. 74/2013**, sem contar o **retrocesso** em termos da efetiva proteção aos necessitados.

Em relação à manifestação do poder constituinte derivado reformador, conforme já estudamos, novamente exemplificando, a EC n. 45/2004, que criou o CNJ (apesar de não ser tribunal inferior, é órgão do Poder Judiciário — art. 92, I-A), bem como extinguiu os tribunais de alçada, não foi nulificada pelo STF. Ainda, a EC n. 24/99, que pôs fim aos juízes classistas, também não foi declarada inconstitucional pela Corte. Aliás, em nenhum momento houve qualquer discussão sobre esse aspecto (*vício formal*) em relação à EC n. 45/2004, também de iniciativa parlamentar, ao estabelecer a autonomia da defensoria pública estadual.

O poder constituinte originário fixou os legitimados para reforma da Constituição, indicados no art. 60, I, II e III (iniciativa concorrente, e não exclusiva do Presidente da República), bem como os limites materiais fixados nas cláusulas pétreas, não se podendo criar outros limites que não esses explicitados. Como se disse, o art. 61, § 1.º, II, “c”, não está direcionado às emendas constitucionais no plano federal.

Consequentemente, não teria sentido o argumento de violação à cláusula pétrea da separação de poderes.

E mais, estabelecer outras restrições significaria impedir a atualização do texto

no contexto da **evolução social** e, assim, “petrificar” a Constituição, oficializando uma nefasta ditadura de um exclusivo legitimado (no caso, o Presidente da República) para os temas ali previstos no art. 61, § 1.º, II.

Além de toda essa argumentação, que já seria suficiente para total improcedência da ADI 5.296, a reforma introduzida pela EC n. 74/2013 não tem nada a ver com “servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria” (art. 61, § 1.º, II, “c”). A previsão da autonomia da Defensoria Pública da União vem ao encontro da realização do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa e do tratamento nacional e uno da instituição, dentro de uma perspectiva de isonomia e de concretização de direitos fundamentais.

Diante do incontestável reconhecimento de autonomia funcional, administrativa e financeira da defensoria pública estadual, do DF e da União (ECs ns. 45/2004, 69/2012 e 74/2013), não se admite a sua vinculação a quaisquer dos Poderes (as disposições são de eficácia plena e aplicabilidade imediata). Estabelecer que a defensoria pública é integrante ou subordinada ao Poder Executivo, diante das regras introduzidas, significa afrontar a Constituição e regredir em termos do direito fundamental de proteção aos necessitados.

Devemos, então, aguardar a posição do STF no julgamento dessa relevante questão esperando que não se reconheçam os argumentos lançados que, sem dúvida, não só são destituídos de fundamentos (insubsistentes), como estão na contramão dos **documentos internacionais**, por exemplo, a *Resolução n. 2.821/2014 da OEA*, que recomenda aos Estados a concessão, aos defensores públicos, de independência e autonomia funcional, financeira e/ou orçamentária e técnica (item 5), como destacado por **Daniel Sarmento** em bem fundamentado parecer dado no sentido da constitucionalidade da EC n. 74/2013. [76](#)

■ 12.6.6. As profundas alterações introduzidas pela EC n. 80/2014

■ 12.6.6.1. Visão topológica

Partindo das alterações estabelecidas pelas ECs ns. 45/2004, 69/2012, 74/2013, podemos dizer que a **EC n. 80/2014** introduziu profundas alterações em relação à Defensoria Pública, trazendo avanços extraordinários e a consolidação de seu reconhecimento constitucional como “**metagarantia**”⁷⁷. A prestação de assistência aos necessitados e vulneráveis não deve ser vista como “favor”, mas direito da sociedade e dever do Estado.

O mais importante, nos parece, diz respeito à sua previsão “topológica”, no capítulo IV, do título IV, da Constituição, agora em **seção separada própria e exclusiva**. Antes da EC n. 80/2014, a Defensoria Pública estava alocada na mesma sessão da Advocacia, conforme se observa abaixo:

REDAÇÃO ORIGINAL (CF/88)	REDAÇÃO DADA PELA EC N. 80/2014
TÍTULO IV CAPÍTULO IV — Das funções essenciais à Justiça ■ Seção I — Do Ministério Público ■ Seção II — Da Advocacia Pública ■ Seção III — Da Advocacia e da Defensoria Pública	TÍTULO IV CAPÍTULO IV — Das funções essenciais à Justiça ■ Seção I — Do Ministério Público ■ Seção II — Da Advocacia Pública ■ Seção III — Da Advocacia ■ Seção IV — Da Defensoria Pública

Podemos dizer, então, que, a partir do advento da EC n. 80/2014, quatro passam a ser as funções essenciais à Justiça, com regras próprias e muito bem delimitadas, o que, então, permite-nos afirmar que a Defensoria Pública está, agora, do ponto de vista institucional, desvinculada da Advocacia.

■ 12.6.6.2. *Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado*

De acordo com o art. 134, *caput*, na redação dada pela EC n. 80/2014, a Defensoria Pública é **instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe**, nos termos do inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal, de forma **integral e gratuita, como expressão e instrumento do regime democrático**, fundamentalmente e em prol dos necessitados:

- a **orientação jurídica**;
- a **promoção dos direitos humanos**;
- a **defesa**, em todos os graus, **judicial e extrajudicial**, dos direitos individuais e coletivos.

■ 12.6.6.3. *Princípios institucionais*

De acordo com o art. 134, § 4.º, da CF/88, introduzido pela EC n. 80/2014, constitucionalizando o que já constava do art. 3.º, da LC n. 80/94, são **princípios institucionais** da Defensoria Pública a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional**, aplicando-se também, no que couber, e aqui a importante novidade, o disposto no **art. 93** e no **inciso II do art. 96** desta Constituição Federal.

Essa nova previsão tem redação idêntica àquela fixada pelo constituinte originário para o Ministério Público nos termos do **art. 127, § 1.º** e, assim, as perspectivas lançadas no *item 12.2.5.1* parecem ser aqui aplicadas.

As regras contidas nos arts. 93 e 96, II, também dão a dimensão atribuída pela EC n. 80/2014 para a Defensoria Pública.

■ 12.6.6.4. *Número de defensores públicos na unidade jurisdicional*

Na “justificação” da *PEC 247/2013*, foi considerado importante estudo, de

recomendável leitura, especialmente pelos governantes, realizado pela *Associação Nacional dos Defensores Públicos — ANADEP* em conjunto com o *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA*, com o apoio e a colaboração do *Ministério da Justiça*, denominado “**Mapa da Defensoria Pública no Brasil**”. Conforme destacado no trabalho, no Brasil, havia “8.489 cargos criados de defensor público dos Estados e do Distrito Federal, dos quais **apenas** 5.054 estão providos (59%). Esses 5.054 defensores públicos se desdobram para cobrir **28%** das comarcas brasileiras, ou seja, na grande maioria das comarcas, o Estado acusa e julga, mas não defende os mais pobres. Na Defensoria Pública da União a situação não é diversa: São 1.270 cargos criados e apenas 479 efetivamente providos, para atender 58 sessões judiciárias de um total de 264, o que corresponde a uma cobertura de 22%”⁷⁸.

Nesse contexto, de acordo com o art. 98, *caput*, do ADCT, também introduzido pela EC n. 80/2014, seguindo a mesma redação que foi dada pela EC n. 45/2004 em relação ao número de juízes, está estabelecido que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva **demanda** pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva **população**. Com isso, assegura-se a eficaz prestação do serviço de assistência, de modo efetivo, e pela carreira da Defensoria Pública.

Para se cumprir essa previsão, foi estabelecido o prazo de **8 anos** a partir do advento da referida emenda, quando, então, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em **todas** as unidades jurisdicionais, observadas as regras acima mencionadas.

Durante esse período, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

Assim, ao final desse período de 8 anos, não mais fará sentido o Estado continuar fazendo convênios com a OAB e outras instituições, já que, de modo muito claro, esse “serviço” de assistência foi fixado para ser prestado pela **carreira da Defensoria Pública**, havendo o dever da realização de concurso público para o cumprimento da meta de defensores proporcional à efetiva

demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva **população**.

■ **12.6.6.5. O defensor público, uma vez nomeado e tendo tomado posse, tem o dever de continuar inscrito nos quadros da OAB?**

Como todos sabem, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, **nos limites da lei** (art. 133 da CF/88).

Já tivemos a oportunidade de destacar que a presença do advogado pode ser dispensada como se observa, para se ter exemplos, nos juizados especiais (art. 20 da Lei n. 9.099/95 e art. 10 da Lei n. 10.259/2001), para a impetração do *habeas corpus*, na Justiça do Trabalho, para a propositura de ações revisionais, nas hipóteses da SV 5 etc.

Assim, diante da omissão constitucional sobre a necessidade de o defensor público continuar inscrito nos quadros da OAB, entendemos que a resposta à pergunta formulada deverá ser dada pelo legislador. Vejamos:

■ **art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 8.906/94** (*Estatuto da Advocacia*): exercem atividade de advocacia, **sujeitando-se ao regime desta lei**, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes, dentre os ali indicados, da **Defensoria Pública**;

■ **arts. 26 e 71 da LC n. 80/94** (*além de dar outras providências, organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados*): o candidato, **no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil**, ressalvada a situação dos proibidos de obtê-la, e comprovar, no mínimo, dois anos de prática forense, devendo indicar sua opção por uma das unidades da federação onde houver vaga;

■ **art. 4.º, § 6.º, da LC n. 80/94** (*introduzido pela LC n. 132/2009*): a **capacidade postulatória** do Defensor Público decorre **exclusivamente** de sua **nomeação** e **posse no cargo público**.

Em nosso entender, a melhor forma de se harmonizar todos os dispositivos

destacados é sustentar que o **registro na OAB é requisito** para a **inscrição no concurso público**, demonstrando, então, ser o candidato advogado.

Uma vez aprovado no certame, em razão de sua **nomeação e posse no cargo**, passa o defensor a ter capacidade postulatória **independentemente de inscrição nos quadros da OAB**, ficando, então, **dispensado de continuar vinculado à Ordem dos Advogados**.

A regra do art. 4.º, § 6.º, da LC n. 80/94, ao usar a palavra **“exclusivamente”**, dispensou a necessidade de continuar inscrito nos quadros da OAB, obrigação esta que deve ser entendida apenas como **requisito de capacitação profissional** para a mera inscrição no certame.

Esse mecanismo, aliás, não é novidade. Em muitas outras situações, o direito brasileiro também exige um certo requisito para uma dada situação, mas não obriga a sua manutenção. Essa situação não traz qualquer afronta à Constituição que, como visto, deixou ao encargo da lei fixar as regras em relação à Advocacia.

Como exemplo, podemos pensar na carreira de delegado de polícia que exige para a aprovação no concurso público, como fase de caráter eliminatório do certame, a aprovação no exame de aptidão física. Manter esse vigor físico cobrado para o ingresso na carreira não é, porém, exigência para depois da posse.

Toda essa argumentação, sem dúvida, encontra mais sentido com a EC n. 80/2014 que desvinculou, de vez, a Defensoria Pública da Advocacia, tanto que agora estão em seções separadas, conforme visto acima. Ousamos afirmar que, do ponto de vista constitucional, a distância em que se encontra a carreira do Ministério Público da Advocacia (seção I e III do capítulo IV do Título IV) é a mesma entre a Defensoria Pública e a Advocacia (seção I e IV do capítulo IV do Título IV). Conforme dissemos, a partir da EC n. 80/2014, as 4 funções essenciais à Justiça estão tratadas de modo individual e distinto.

A maior aproximação ou não, em termos de requisitos, dependerá da prescrição normativa que, conforme visto, estabeleceu que a **capacidade postulatória** do Defensor Público decorre **exclusivamente** de sua **nomeação e**

posse no cargo público.

Diante dessa argumentação, entendemos que deveria ter sido modificado, também, o art. 94 da CF/88, quando define as regras para o “**quinto constitucional**” para que se permita, sem qualquer tipo de retaliação política, a efetiva participação de defensores que deixaram de estar inscritos nos quadros da OAB.

Sem dúvida, estamos diante de relevante problemática a ser enfrentada pela doutrina e pelo STF (pendente).

■ 12.6.7. Existe Defensoria Pública Municipal?

Não, assim como não há MP e Judiciário municipais. Na verdade, existem núcleos da Defensoria Pública, tanto a Federal como a Estadual, nos Municípios.

■ 12.6.8. Princípio do defensor público natural

Conforme vimos, além de as partes serem julgadas por órgão independente e pré-constituído, o acusado tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, **vedando-se**, por consequência, a **designação arbitrária**, inclusive, de **promotores *ad hoc*** ou **por encomenda** (art. 5.º, LIII, e art. 129, I, c/c o art. 129, § 2.º).

Nesse sentido, de maneira bastante adequada, assegura-se aos **necessitados**, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal, o direito de serem patrocinados por **defensor público natural** (art. 4.º-A, IV, da LC n. 80/94, introduzido pela LC n. 132/2009), investido na carreira por concurso público de provas e títulos.

Assim, referidos **concursos públicos** para o preenchimento dos cargos de **defensores públicos** de todo o Brasil devem ser implementados, evitando que os convênios com a OAB continuem sendo um fator impeditivo do cumprimento desse mandamento constitucional, [79](#) especialmente, conforme vimos, com o

advento da **EC n. 80/2014** que fixou o prazo de **8 anos** para que a União, os Estados e o Distrito Federal passem a contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, em número proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

Se não admite a contratação temporária de juízes de direito, ou convênios para acusação, naturalmente a sociedade não pode aceitar que a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na forma do art. 5.º, LXXIV, sejam implementadas mediante convênio, ou contratação temporária. A Constituição exige que esse “serviço” de assistência jurídica, integral e gratuita, seja prestado por defensores públicos investidos em cargos de carreira e providos por concurso público.

■ **12.6.9. Algumas problemáticas já decididas pela jurisprudência do STF e do STJ**

■ **12.6.9.1. A indispensabilidade do concurso público para ingresso na carreira**

O art. 134, § 1.º (renumerado pela **EC n. 45/2004**), estabelece a **necessidade** de **concurso público de provas e títulos** para o **ingresso** na carreira, devendo apenas ser observado o art. 22 do ADCT, que assegura aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, independentemente, **para essa situação específica**, da forma de investidura,^{[80](#)} com a observância das garantias e vedações previstas no referido art. 134, § 1.º, da Constituição.

Com base nessas regras, qualquer outra forma de investidura na carreira sem concurso público deverá ser refutada, sendo inconstitucionais as leis que assim estabelecerem (cf. arts. 5.º, *caput*; 37, *caput*, II e V, e precedentes do *STF*: ADI 1.267/AP, Rel. Min. Eros Grau, 30.09.2004 (*Inf. 363/STF*); ADI 1.219-MC/PB (*DJU* de 31.03.1995); ADI 2.125-MC/DF (*DJU* de 29.09.2000); ADI 1.500/ES (*DJU* de 16.08.2002); ADI 2.229/ES, Rel. Min. Carlos Velloso, 09.06.2004) etc.

■ **12.6.9.2. Servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no “exercício regular” de suas funções tem direito à “assistência judiciária” do Estado? Essa atribuição pode ser destinada à Defensoria Pública Estadual?**

O STF entendeu, ao apreciar o art. 45 da CE/RS (“o servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções terá direito à assistência judiciária do Estado”), que referida regra “... **não** viola a CF, uma vez que apenas outorga, de forma ampla, um direito funcional de proteção do servidor que, agindo regularmente no exercício de suas funções, venha a ser processado civil ou criminalmente...”.

Contudo, “... em relação à alínea *a* do Anexo II da Lei Complementar gaúcha 10.194, de 30 de maio de 1994, que definia como atribuição da Defensoria Pública estadual a assistência judicial aos servidores processados por ato praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais, o STF (...) considerou-se que **a norma ofendia o art. 134 da CF**, haja vista alargar as atribuições da Defensoria Pública estadual, extrapolando o modelo institucional preconizado pelo constituinte de 1988 e comprometendo a sua finalidade constitucional específica”. Nesse ponto, “... por maioria, atribuiu-se o efeito dessa decisão a partir do dia 31.12.2004, a fim de se evitar prejuízos desproporcionais decorrentes da nulidade *ex tunc*, bem como permitir que o legislador estadual disponha adequadamente sobre a matéria” (ADI 3.022/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJ* de 18.08.2004 — *Inf.* 355/STF).

Assim, a chamada “assistência judiciária”, em razão de ato praticado no **exercício regular** de suas funções, está reconhecida pelo STF, mas desde que prestada pelo **Procurador de Estado**,⁸¹ e não pelo Defensor Público estadual, sob pena de violar a **finalidade constitucional específica** da Defensoria, que é a prestação da assistência jurídica integral e gratuita **aos que comprovarem insuficiência de recursos**.

Naturalmente, se o servidor assim for considerado (“insuficiência de recursos”), poderá requerer o patrocínio da Defensoria, mas a regra não pode ser generalizada para todo servidor público do Estado.

■ **12.6.9.3. Prazo em dobro e intimação pessoal: prerrogativas da Defensoria Pública. A questão da regra do prazo em dobro para o processo penal. “Lei ainda constitucional”**

Nos termos dos arts. 44, I; 89, I; e 128, I, da LC n. 80/94, é prerrogativa dos membros da Defensoria Pública receber **intimação pessoal** em qualquer processo e grau de jurisdição,⁸² contando-se-lhes em **dobro todos os prazos, regra esta também prevista no CPC/2015 (art. 186, caput e § 1.º).**⁸³

Para o **processo civil**, a regra não sofreu nenhuma repreensão por parte do STF, até porque há equivalente para o MP e a Fazenda Pública nos termos do art. 188 do CPC/73 (o CPC/2015 estabeleceu para o MP — art. 180, para a Advocacia Pública — art. 183 e para a Defensoria Pública — art. 186, a **regra do prazo em dobro** para **todas as manifestações processuais**, não se falando mais em prazo em quádruplo para contestar, conforme previsto no art. 188 do CPC/73).

Mas, para o **processo penal**, no que tange ao **prazo em dobro**, na medida em que o MP não goza de tal prerrogativa, questionou-se se, de fato, a regra poderia ser estabelecida para a Defensoria Pública quando atua como defensora de acusação formulada pelo MP, especialmente em face dos princípios da isonomia e do devido processo legal.

O STF, ao examinar o tema do **prazo em dobro para o processo penal**, entendeu que referida regra é constitucional até que a Defensoria Pública efetivamente se instale. Trata-se do que já estudamos e chamamos de “lei ainda constitucional”, ou “lei em trânsito para a inconstitucionalidade”, ou “inconstitucionalidade progressiva” (*item 6.7.1.6*, em que analisamos o precedente do **HC 70.514**).

Assim, o prazo em dobro para o processo penal só valerá enquanto a Defensoria Pública ainda não estiver eficazmente organizada. Quando tal se verificar, a regra tornar-se-á **inconstitucional**.

Isso significa que referida regra poderá ser **“ainda constitucional”** em determinado Estado, que está implementando a Defensoria, mas inconstitucional em outro, que já eficazmente instalou a Defensoria.

■ **12.6.9.4. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para Procuradores do Estado no exercício da assistência judiciária, como foi o caso de São Paulo?**

Conforme vimos, os arts. 44, I; 89, I; e 128, I, da LC n. 80/94 fixaram como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública receber **intimação pessoal** em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em **dobro todos os prazos**, regra também prevista no CPC/2015 (art. 186, *caput* e § 1.º).

O art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/50 (acrescentado pela Lei n. 7.871/89), por sua vez, estabeleceu que nos Estados onde a assistência judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, **ou quem exerça cargo equivalente**, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Assim, o STF decidiu que “aos procuradores dos Estados no exercício de assistência judiciária é reconhecida a prerrogativa do recebimento de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição (art. 128, I, da LC 80/94), porquanto investidos na função de defensor público” (*Inf. 251/STF*). [84](#)

■ **12.6.9.5. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para os advogados dativos?**

O candidato estudioso e os advogados devem ficar bem atentos neste ponto, em relação aos advogados dativos, na medida em que inexistente **vínculo estatal**, diferentemente do que acontece com os Procuradores do Estado ou com quem exerce cargo (público) equivalente.

Pedimos vênias, aqui, para transcrever texto publicado no *Inf. 219/STF* que reproduz o entendimento do STF em um primeiro momento: “**não** se estendem aos **defensores dativos** as prerrogativas processuais da intimação pessoal e do prazo em dobro asseguradas aos **defensores públicos em geral** e aos **profissionais que atuam nas causas patrocinadas pelos serviços estaduais de assistência judiciária** (Lei n. 7.871/89 e LC 80/94) (...). Precedentes citados: Pet. 932-SP (*DJU* de 14.09.1994) e AG 166.716-RS (*DJU* de

25.05.1995). CR (AgRg-AgRg) 7.870 — Estados Unidos da América, Rel. Min. Carlos Velloso, 07.03.2001. (CR-7870)”.

No STJ, a 3.^a Seção e as 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a Turmas assim se posicionaram, mas apenas em relação ao **prazo em dobro**: “a contagem em dobro dos prazos processuais, prevista no art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/50, somente é aplicável nos feitos em que atue *Defensor Público ou integrante do serviço estatal de assistência judiciária*, **não se incluindo nessa condição o defensor dativo e o advogado particular, mandatário de beneficiário da justiça gratuita**”.

No tocante à **intimação pessoal em matéria penal**, cuidado! A regra é nova, superando o entendimento anterior do STF. Mas, vejam, em relação, somente, à intimação pessoal.

Para saber se o dativo tem direito à intimação pessoal, devemos analisar qual o momento do ato. Se a intimação se deu antes da **Lei n. 9.271/96**, que incluiu o § 4.º no art. 370 do CPP, vale a regra citada no *Inf. 219/STF*, qual seja, a **inexistência** do direito à intimação pessoal para o dativo. Por outro lado, se a intimação se deu após o advento da referida lei, o dativo deve ser intimado **pessoalmente**.⁸⁵

“A partir da edição da Lei 9.271/96, que incluiu o § 4.º ao art. 370 do CPP, os defensores nomeados, dentre os quais se inclui o **defensor dativo**, passaram também a possuir a **prerrogativa da intimação pessoal**. Com base nesse entendimento, a Turma, por maioria, indeferiu *habeas corpus* em que se pretendia a anulação de ação penal, em virtude da ausência de intimação pessoal de defensor dativo para o julgamento de apelação. Sustentava-se, na espécie, a obrigatoriedade dessa intimação, sob o argumento de que a Lei 1.060/50 não fez distinção entre defensores dativo e público. Considerando que, no caso, a intimação do defensor dativo da pauta de julgamento da apelação ocorrera via publicação no *Diário de Justiça*, em data anterior ao advento da mencionada Lei 9.271/96, entendeu-se incidente o princípio do *tempus regit actum*, a afastar a exigência legal. Vencido o Min. Marco Aurélio, que, tendo em conta a peculiaridade da inexistência, à época, de defensoria pública no Estado de São Paulo, deferia o *writ* para tornar insubsistente o julgamento da apelação,

determinando que outro se realizasse com a intimação pessoal do defensor dativo, ao fundamento de que a Lei 1.060/50 previa não só a intimação do próprio defensor público, como também daquele que atuasse em sua substituição. Precedente citado: HC 89.315/SP (DJU de 13.10.2006). **HC 89.710/SP**, Rel. Min. Cármen Lúcia, 12.12.2006” (Inf. 452/STF).

Assim, como anota o Ministro Lewandowski, no precedente da matéria (**HC 89.315**), “... com o advento da Lei n. 9.271/96, que incluiu o § 4.º ao art. 370 do CPP, tornou-se obrigatória a intimação pessoal dos defensores nomeados, sejam eles defensores públicos, procuradores da assistência judiciária ou defensores dativos” (j. 19.09.2006, DJ de 13.10.2006).

Resumindo, ao advogado dativo, de acordo com o entendimento do STF:

- **não** há a prerrogativa do prazo em dobro;
- em relação à **intimação pessoal em matéria penal**, depende do momento do ato (*tempus regit actum*). Se a intimação se deu antes da Lei n. 9.271/96, que incluiu o § 4.º ao art. 370 do CPP, **não** há a prerrogativa da intimação pessoal para o dativo;[86](#)
- contudo, se a intimação está sendo realizada (em matéria penal) **após** o advento da Lei n. 9.271/96, o advogado dativo deve ser intimado pessoalmente, nos termos do art. 370, § 4.º, do CPP.

■ **12.6.9.6. As prerrogativas do prazo em dobro e intimação pessoal para a Defensoria Pública aplicam-se ao rito especial dos Juizados?**

NÃO.

Em observância aos princípios da **celeridade**, **isonomia** e **especialidade**, a *Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais junto ao Conselho da Justiça Federal* entendeu que o prazo em dobro para a Defensoria Pública não se aplica ao rito dos juizados especiais.[87](#)

“No pedido de uniformização, a Turma Nacional não acatou a tese da DPU relativa ao prazo privilegiado, considerando que o fato de a Lei Complementar conferir a prerrogativa de prazo em dobro para os defensores públicos não

autoriza a Turma Nacional a privilegiá-los no âmbito dos Juizados Especiais Federais, uma vez que os Juizados são guiados pelo princípio da isonomia entre as partes. O art. 9.º da Lei n. 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Federais, diz que nenhuma pessoa jurídica de Direito Público goza de prazos privilegiados”.[88](#)

O STF, por seu turno, em relação à intimação pessoal, já se posicionou: “é **dispensável**, no âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal das partes, inclusive do representante do Ministério Público e defensores nomeados, bastando que a mesma se faça pela imprensa oficial. Afasta-se, dessa forma, o § 4.º do art. 370 do CPP, para a aplicação, com base no **princípio da especialidade**, do § 4.º do art. 82 da Lei 9.099/95 (‘as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa’)...”.[89](#)

Nessa linha, o art. 7.º da **Lei n. 12.153, de 22.12.2009**, que institui os **Juizados Especiais da Fazenda Pública**, estabelece que **não haverá prazo diferenciado** para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias.

■ **12.6.9.7. Como ficou a prerrogativa do prazo em dobro e da intimação pessoal no CPC/2015?**

Conforme vimos, de acordo com o art. 186 do CPC/2015, a Defensoria Pública gozará de prazo em **dobro** para todas as suas manifestações processuais, tendo início com a **intimação pessoal do defensor público** por carga, remessa ou meio eletrônico (art. 183, § 1.º).

Importante inovação está prevista no art. 186, § 4.º, ao estabelecer que a prerrogativa do **prazo em dobro** aplica-se aos **escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito** reconhecidas na forma da lei e às **entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública**.[90](#)

Veja que a nova regra estende apenas a prerrogativa do **prazo em dobro** e

não faz distinção entre faculdades de direito **públicas** ou **privadas**.

■ **12.6.9.8. Defensor público pode exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais?**

NÃO.

De acordo com o art. 134, § 1.º, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e **vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais**.[91](#)

Resumindo, o defensor público só pode advogar para cumprir a sua missão constitucional, que é a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

E como ficam os defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte? Em relação a eles, também, está vedada a advocacia fora de suas atribuições institucionais, nos termos do **art. 22 do ADCT**, que assegura a opção pela carreira da Defensoria desde que se observem as **garantias** e **vedações** previstas no art. 134, § 1.º, da Constituição. Como vedação, portanto, está a proibição de prestar o serviço de advocacia fora dos ditames constitucionais.

■ **12.6.9.9. Inconstitucionalidade progressiva — art. 68 do CPP — “lei ainda constitucional”**

Conforme vimos ao estudar o assunto (*item 6.7.1.6.1.2*), a atribuição de legitimidade ao MP para o ajuizamento de ação civil *ex delicto*, em tese, violaria a finalidade específica da Defensoria Pública, que tem a missão constitucional de defesa dos necessitados, na forma da lei.

A Defensoria Pública, no entanto, em muitos Estados, ainda está em vias de

efetiva implementação.

Assim, o STF vem decidindo, de maneira acertada, que o art. 68 do CPP é uma lei “**ainda constitucional**” e que está **em trânsito, progressivamente, para a inconstitucionalidade**, à medida que as Defensorias Públicas forem, **efetiva** e **eficazmente**, sendo instaladas. [92](#)

Vale dizer, instalada eficazmente a Defensoria, a ação não mais poderá ser ajuizada pelo MP, devendo ser assumida pelo defensor, inclusive, em nossa opinião, em processos que estiverem em curso.

■ 12.6.9.10. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública?

SIM.

A Lei n. 11.448, de 15.01.2007, ao alterar o art. 5.º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública — LACP), legitimou a **Defensoria Pública** para o ajuizamento da ação civil pública.

A ampliação da legitimação ativa foi questionada no STF pela CONAMP, na **ADI 3.943**, por supostamente contrariar o art. 5.º, LXXIV e o art. 134, *caput*, da Constituição Federal, em sua redação original, antes da EC n. 80/2014.

A ação foi proposta em 16.08.2007 e julgada em 07.05.2015, praticamente 8 anos depois.

A Corte, por unanimidade (8 x 0), julgou **improcedente** o pedido, declarando, assim e acertadamente, a **constitucionalidade** da Lei n. 11.448/2007. [93](#)

Devemos lembrar que a LC n. 132/2009 introduziu importantes regras à LC n. 80/94, reforçando e ampliando a atribuição destinada à Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública (cf. art. 1.º — cuja redação agora está no art. 134, *caput*, da CF/88, introduzido pela EC n. 80/2014; art. 4.º, VII, VIII e XI; art. 15-A; art. 106-A etc.).

Em sustentação oral por nós realizada em nome da *Associação Nacional dos Defensores Públicos — ANADEP*, apresentamos uma preliminar de prejudicialidade da ADI por não ter havido o aditamento da petição inicial em

razão do advento da referida lei complementar que, em nosso entender, revogou o art. 5.º, II, da LACP, mas essa tese só foi admitida pelo Ministro Teori Zavascki.

No mérito, na linha do que defendemos, a Corte reconheceu com muita propriedade a legitimação da Defensoria Pública, seja pelo contexto do processo coletivo e das novas perspectivas lançadas pelas necessidades da sociedade de massa, seja em razão da regra do **art. 129, § 1.º**, da CF/88, ao prescrever que a legitimação do Ministério Público para o ajuizamento de ações civis (e, no caso, da *ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos* — art. 129, III, da CF/88) **não impede a de terceiros**, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na **Constituição** e na **lei**.

E foi em razão dessa abertura (não exclusividade do Ministério Público) que o legislador, de maneira acertada, prescreveu a legitimação ativa também para a Defensoria Pública: o art. 5.º da Lei da Ação Civil Pública estabelece uma legitimação **extraordinária** (haverá substituição da coletividade), **autônoma** (a presença do legitimado ordinário quando identificado é totalmente dispensada), **concorrente** (em relação aos representantes adequados entre si que concorrem em igualdade para a propositura da ação civil pública) e **disjuntiva** (qualquer legitimado poderá propor a ação sem a anuência, intervenção ou autorização dos demais, sendo o litisconsórcio eventualmente formado sempre facultativo).

Não haveria sentido prever a possibilidade de defesa individual (“atomizada”) e não a admitir de modo coletivo (“molecularizada”), com todas as vantagens do processo coletivo. Como se sabe, essa ampliação agora está expressa na Constituição, no art. 134, *caput*, na redação bastante adequada trazida pela EC n. 80/2014 (não estamos sugerindo uma suposta constitucionalidade superveniente em razão da EC n. 80/2014 na medida em que a redação original dava guarida às regras trazidas pela lei ao se remeter ao art. 5.º, LXXIV, que assegura a assistência jurídica **integral**, abarcando, então, a tutela coletiva).

O Ministro Teori Zavascki, bem como os Ministros Lewandowski e Barroso chegaram a apontar os parâmetros estabelecidos no art. 5.º, LXXIV, que

estabelece ser dever do Estado prestar a assistência jurídica, **integral** e gratuita aos que **comprovarem insuficiência de recursos**. Assim, não poderia a Defensoria Pública defender **apenas** interesses de pessoas que não necessitam dos seus serviços por poderem contratar um advogado.

Apesar desse limite, não haveria qualquer problema em se propor a ação civil pública e, **reflexamente**, o seu **resultado** também beneficiar os que não são necessitados.

Nesse sentido, destacamos o art. 4.º, VII, da LC n. 80/94 (introduzido pela LC n. 132/2009), ao estabelecer ser **função institucional da defensoria pública**, entre outras, a de promover **ação civil pública** e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos **quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes**.⁹⁴

Essa situação, sem dúvida, será observada especialmente quando o objetivo da demanda for **interesse ou direito difuso**, assim entendido, para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, os **transindividuais**, de **natureza indivisível**, de que sejam **titulares pessoas indeterminadas** e ligadas por **circunstâncias de fato** (art. 81, parágrafo único, I, do CDC).

Como exemplo, imaginemos que a Defensoria Pública firme um termo de ajustamento de conduta com uma empresa de ônibus para que o ponto final da linha seja próximo da penitenciária, e não a 5 km de distância. Esse acordo beneficiará não só hipossuficientes, mas, também, todos que pegarem aquela linha de ônibus. A extensão é uma decorrência da indivisibilidade do objeto da demanda. Não significa estar a Defensoria litigando em nome de não necessitados.

Podemos pensar, ainda, em um termo de ajustamento de conduta visando facilitar a gratuidade do transporte público para as pessoas com deficiência física. Ainda, uma ação civil pública objetivando a melhoria de posto de saúde, ou a manutenção do FIES (em um contexto de proteção ao direito fundamental à educação), ou a suspensão do aumento da passagem de ônibus em determinado município, ou a ação contra uma empresa poluente, com o objetivo

de proteção ambiental, ou uma ação objetivando a garantia de fornecimento de água para uma comunidade inteira, ou, ainda, para garantia aos presos de determinada região de condições adequadas de higiene, limpeza, alimentação etc. [95](#)

Em todas essas situações, o resultado da demanda, além de beneficiar pessoas hipossuficientes, também poderá produzir efeitos em relação àqueles que não são necessitados. Estamos diante daquilo que a doutrina norte-americana chamou de *free rider*, ou seja, o “carona” [96](#), que **também** se beneficiará com o resultado da demanda. Essa **consequência prática** não afronta a Constituição mas, como visto, decorre da natureza jurídica do objeto (indivisibilidade dos direitos ou interesses difusos).

■ **12.6.9.11. O Defensor Público pode receber honorários advocatícios? Como ficou no CPC/2015?**

Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública é **vedado**, segundo a lei orgânica, **receber**, a qualquer título e sob qualquer pretexto, **honorários**, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições.

Porém, nos termos do art. 4.º, XXI, da LC n. 80/94, são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber as **verbas sucumbenciais** decorrentes de sua atuação, **inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos**, reservando-as a **fundos** geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

Cabe alertar que, no dia **03.03.2010**, a Corte Especial do **STJ** editou a **Súmula 421**, que tem o seguinte teor: “os honorários advocatícios **não são devidos** à Defensoria Pública quando ela atua **contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença**”.

Com todo o respeito, não concordamos com essa orientação, especialmente porque, em razão das reformas constitucionais (ECs ns. 45/2004, 69/2012 e

74/2013), as Defensorias Públicas passaram a ter ampla autonomia funcional, administrativa e financeira.

A regra da LC n. 80/94 parece bastante razoável sobretudo porque os honorários advocatícios, que são devidos em razão da condenação nas verbas sucumbenciais, não sairão de “um bolso” para voltar para “o mesmo bolso”. A destinação do dinheiro será para **fundos** geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

Portanto, mais uma vez, com o máximo respeito, não concordamos com a posição do STJ; resta, pois, aguardar a solução a ser dada pelo STF (**matéria pendente**).

Finalmente, conforme já alertamos (*item 12.3.9*), o art. 85, § 19, do **CPC/2015**, estabelece que “os **advogados públicos** perceberão honorários de sucumbência, **nos termos da lei**”.

De acordo com o art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 8.906/94 (*Estatuto da Advocacia*), exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, **além do regime próprio a que se subordinem**, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da **Defensoria Pública** e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.

Assim, a regra do CPC/2015 reforça o entendimento exposto, já que a nova lei processual delega a previsão e regulamentação para a **lei**, no caso, o art. 4.º, XXI, da **LC n. 80/94**.

■ **12.6.9.12. O Defensor Público tem a garantia da vitaliciedade ou a da estabilidade?**

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu que o Defensor Público, após dois anos de exercício na função, não perderia o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.

Essa questão foi levada ao STF, que julgou ser **inconstitucional** a referida

previsão (cf. ADI 230/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1.º.02.2010, *DJE* de 30.10.2014).

Isso porque, nos termos do art. 41, são **estáveis** após **3 anos** de efetivo exercício os **servidores** nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, podendo perder o cargo:

- em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
- mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

■ **12.6.9.13. O Defensor Público tem a garantia da inamovibilidade?**

SIM.

De acordo com o art. 134, § 1.º, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da **inamovibilidade** e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

■ **12.6.9.14. Remuneração**

A Constituição assegura aos Defensores Públicos a remuneração exclusivamente por **subsídio**, bem como a sua **irredutibilidade** (art. 135 c/c o art. 39, § 4.º).

Nesse sentido, na dicção do art. 37, XV, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI (qual seja, **subteto**, limitado a **90,25%** do subsídio mensal de Ministro do STF) e XIV (do art. 37) e nos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e

■ 12.6.9.15. O Defensor Público tem poder de requisição?

A questão foi examinada pelo STF no julgamento da **ADI 230/RJ** (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1.º.02.2010, *DJE* de 30.10.2014), relativa à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que estabelecia ser **prerrogativa** do Defensor Público **requisitar**, *administrativamente, de autoridade pública e dos seus agentes ou de entidade particular: certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências, necessários ao exercício de suas atribuições.*

Essa previsão, aliás, está explicitada em diversas passagens da **LC n. 80/94**, destacando-se:

- **art. 8.º, XVI:** atribuição do Defensor Público-Geral Federal;
- **art. 8.º, XIX:** atribuição do Defensor Público-Geral Federal — nesse ponto avançando ao se referir à requisição de força policial;
- **art. 44, X:** prerrogativa dos membros da Defensoria Pública da União;
- **art. 56, XVI:** atribuição do Defensor Público-Geral do Distrito Federal e dos Territórios;
- **art. 89, X:** prerrogativa dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
- **art. 128, X:** prerrogativa dos membros da Defensoria Pública do Estado.

O STF, contudo, ao analisar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, entendeu ser o referido poder de requisição **inconstitucional** por estarem sendo conferidas “... ao defensor público prerrogativas que implicariam, além de interferência em outros poderes, prejuízo na paridade de armas que deve haver entre as partes” (*Inf. 573/STF*), havendo “exacerbação das prerrogativas asseguradas aos demais advogados”.

Conforme noticiado, “seguiu-se um debate sobre a interpretação conforme,

com a preocupação de não se criar um ‘superadvogado’, com ‘superpoderes’, o que quebraria a igualdade com outros advogados, que precisam ter certos pedidos deferidos pelo Judiciário” (*Notícias STF*, 1.º.02.2010).

Essa deve ser a tendência para a solução dos dispositivos da LC n. 80/94 que fixam a prerrogativa de requisição no mesmo sentido.

■ **12.6.9.16. A Defensoria Pública Estadual e a Distrital podem atuar nos Tribunais Superiores?**

SIM.

A questão foi discutida pelo STF, que entendeu **não** haver **exclusividade** da Defensoria Pública da União de atuação em Tribunais Superiores, como, no caso, no STJ. [97](#)

Isso porque, nos termos do art. 106, *caput*, e parágrafo único, da LC n. 80/94, a **Defensoria Pública do Estado** prestará assistência jurídica aos necessitados, em **todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado**, competindo-lhe interpor recursos aos Tribunais Superiores, quando cabíveis.

Esse entendimento, bem como a previsão normativa, encontram fundamento no art. 134, *caput*, que não faz qualquer distinção entre a Defensoria Pública da União e as dos Estados e do DF, quando incumbe-lhes a atuação em **todos os graus**, judicial e extrajudicialmente.

■ **12.6.9.17. É constitucional a imposição por ato normativo da obrigatoriedade de convênio a ser firmado entre a Defensoria Pública e a OAB, para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita?**

NÃO.

De acordo com a decisão do STF, “é **inconstitucional** toda norma que, impondo a Defensoria Pública Estadual, para prestação de serviço jurídico integral e gratuito aos necessitados, a obrigatoriedade de assinatura de convênio exclusivo com a Ordem dos Advogados do Brasil, ou com qualquer outra

entidade, viola, por conseguinte, a autonomia funcional, administrativa e financeira daquele órgão público” (**ADI 4.163**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.02.2012, Plenário, *DJE* de 1.º.03.2013).

No mais, é de destacar, na linha dos argumentos expostos pelos Ministros, que a **regra** primordial para a prestação dos serviços de assistência, haja vista ser atividade estatal, essencial e permanente, é a do **concurso público**, admitindo-se a situação dos não concursados em caráter **excepcional** e de modo **temporário**.

Assim, está autorizada, sem obrigatoriedade, necessidade ou exclusividade, a celebração, pela Defensoria, a seu critério e em virtude de sua autonomia administrativa e funcional, de convênio com a OAB.

Não se pode confundir tal autorização com a prestação dos serviços exclusivamente em razão de convênio firmado com a OAB.

Em caso concreto, no Estado de Santa Catarina, a assistência era prestada pelo intitulado serviço de “defensoria pública dativa”, não se utilizando da parceria de forma suplementar ou para suprir eventuais carências, já que a carreira não estava instituída.

Diante dessa situação extrema, o STF, no julgamento das **ADIs 3.892 e 4.270** (j. 14.03.2012), nulificou as leis estaduais que davam amparo a essa sistemática, admitindo a continuidade dos serviços que estavam sendo prestados pelo prazo máximo de 1 ano da data do julgamento da ação (*modulação dos efeitos da decisão*), sendo que, ao final, deveria estar em funcionamento órgão estadual de defensoria pública, estruturado de acordo com a Constituição e em estrita observância à LC n. 80/94. [98](#)

■ 12.7. QUESTÕES [99](#)

■ 12.7.1. Ministério Público

1. (MP/78.º/SP) Leis que organizem o Ministério Público da União e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo são, respectivamente, de iniciativa privada:

- a) da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa;
- b) do Presidente da República e do Governador do Estado;
- c) do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral do Estado;
- d) do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa;
- e) da Câmara dos Deputados e do Procurador-Geral do Estado.

2. (MP/74.º/Matéria Complementar/SP) Ausente o Promotor que iria officiar em sessão do Tribunal do Júri, pode o Juiz Presidente, para evitar o adiamento, nomear Promotor *ad hoc*? Justifique.

3. (MP/73.º/Matéria Complementar/SP) Quais são os princípios institucionais do Ministério Público?

4. (MP/73.º/Matéria Complementar/SP) Em que consiste a vitaliciedade do membro do Ministério Público?

5. (MP/73.º/Matéria Complementar) O membro do Ministério Público pode participar de sociedade comercial?

6. (MP/75.º/Matéria Complementar/SP) Como é escolhido e destituído o Procurador-Geral de Justiça?

7. (MP/75.º/Matéria Complementar/SP) Como são resolvidos os conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público de primeira instância?

8. (MP/78.º/SP) Tício, aprovado em concurso de provas e títulos, é nomeado Promotor de Justiça Substituto do Estado de São Paulo. Toma posse perante o Procurador-Geral de Justiça, em sessão solene do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, mas deixa de entrar em exercício no prazo legal. A autoridade administrativa competente deverá:

- a) proclamar o abandono do cargo;
- b) abrir sindicância administrativa a fim de apurar os fatos;
- c) revogar a nomeação, aproveitando a vaga de acordo com a ordem de classificação no concurso;
- d) promover o anulamento da nomeação, declarando vago o cargo, para provimento futuro;
- e) desligá-lo do cargo.

9. (MP/79.º/SP) Qual destes órgãos prescinde, em sua composição, de membros do Ministério Público?

- a) Superior Tribunal de Justiça;
- b) Superior Tribunal Militar;
- c) Tribunal Superior do Trabalho;
- d) Tribunal Superior Eleitoral;
- e) Tribunal de Contas da União.

10. (MP/79.º/SP) O Corregedor-Geral do Ministério Público é eleito:

- a) pelo Colégio de Procuradores;
- b) pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores;
- c) pelo Conselho Superior do Ministério Público;
- d) por todos os integrantes da carreira;
- e) por todos os integrantes da carreira, exceto os não vitalícios.

11. (MP/79.º/SP) Compete ao Conselho Superior do Ministério Público decidir:

- a) sobre o vitaliciamento de membro do Ministério Público;
- b) sobre as normas da organização das Procuradorias de Justiça;
- c) sobre as normas do concurso de ingresso à carreira do Ministério Público;
- d) sobre o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar;
- e) sobre o afastamento de membro do Ministério Público da carreira.

12. (MP/82.º/SP) A Constituição Federal não atribui ao Ministério Público a função institucional de:

- a) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- b) representar judicialmente entidades públicas;
- c) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- d) exercer o controle externo da atividade policial;
- e) exercer funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

13. (Magistratura MG — 2004/2005) Não se compreende nas funções institucionais do Ministério Público:

- a) expedição de notificações nos procedimentos administrativos de sua competência;
- b) representação judicial de entidades públicas;

- c) exercício do controle externo da atividade policial, na forma de lei complementar;
- d) defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas;
- e) requisição de diligências investigatórias e instauração de inquérito policial.

14. (PROC/MP/MG/2007) De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado, dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, pelo:

- a) Conselho Nacional do Ministério Público, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de três anos, permitida a recondução.
- b) Presidente da República, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- c) Supremo Tribunal Federal, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- d) Presidente da República, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- e) Presidente da República, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de três anos, permitida a recondução.

15. (Analista Judiciário/TSE/2007) O Ministério Público Eleitoral:

- a) é um órgão do Ministério Público da União.
- b) é um órgão do Ministério Público Federal.
- c) é um órgão do Ministério Público dos Estados.
- d) não integra o rol dos órgãos do Ministério Público definido pela Constituição da República.

16. (Delegado-TO/CESPE/UnB-2008) Entre as funções institucionais do Ministério Público, estão o controle da atividade policial e a requisição de diligências investigatórias e da instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

17. (Analista judiciário/PB/TJ PB 2008) NÃO constitui função institucional do Ministério Público:

- a) Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição.

- b) Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
- c) Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.
- d) Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência.
- e) Exercer o controle interno da atividade policial.

18. (Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia — FCC 2010) Os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas dos Estados

- a) possuem estabilidade após três anos de efetivo exercício do cargo.
- b) estão administrativamente vinculados ao Ministério Público do Estado, embora exerçam funções junto ao Tribunal de Contas.
- c) atuam como procuradores do Tribunal de Contas, devendo defender os interesses deste órgão.
- d) podem exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram após três anos do afastamento por aposentadoria ou exoneração.
- e) não podem exercer outra função pública, exceto uma de magistério, a não ser que estejam em disponibilidade.

19. (50.º MP/MG — 2010) Segundo dicção expressa da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público:

- I. o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros;
- II. rever mediante provocação, exclusivamente, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
- III. receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, apenas no caso de omissão do órgão correcional da instituição;
- IV. zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) apenas em I e III.
- b) apenas em II.
- c) apenas em I e IV.

d) apenas em II e III.

20. (Técnico Judiciário — Área Administrativa — FCC/2012/TST) Ao discorrer sobre os princípios constitucionais que devem informar a atuação do Ministério Público, Pedro Lenza afirma que o acusado “tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por consequência, a designação arbitrária, inclusive, de promotores *ad hoc* ou por encomenda” (*Direito Constitucional Esquematizado* — Saraiva — 2011 — p. 766).

Trata-se do princípio

- a) da inamovibilidade do membro do Ministério Público.
- b) da independência funcional do membro do Ministério Público.
- c) da indivisibilidade do Ministério Público.
- d) da unidade do Ministério Público.
- e) do promotor natural.

21. (Ministério Público/SC — 2013 — manhã) Analise o enunciado da questão abaixo e assinale “certo” ou “errado”:

No exercício de sua competência constitucional e correicional da instituição, o CNMP pode avocar processos disciplinares em curso em quaisquer unidades do Ministério Público Brasileiro.

■ 12.7.2. Advocacia

1. (OAB/109.º) Em procedimento administrativo disciplinar instaurado contra funcionário público em determinado órgão do Poder Executivo, o advogado do funcionário, ao apresentar defesa, emitiu opinião desfavorável a respeito da conduta do funcionário chefe do seu cliente. Sentindo-se ofendido em sua honra, o funcionário chefe iniciou ação penal por crime de injúria contra o advogado. Habeas corpus impetrado em favor do advogado trancou a ação penal, sob o fundamento:

- a) da liberdade de expressão, independentemente de censura;
- b) da liberdade de manifestação do pensamento;
- c) da inviolabilidade do advogado por manifestações no exercício da profissão;
- d) da aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. (Analista Judiciário TRT 9.^a R. Administrativa — FCC 2010) Em matéria de funções essenciais à Justiça, analise:

- I. Representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
- II. Representação judicial das respectivas unidades federadas, salvo o Distrito Federal.

As referidas representações cabem, respectivamente:

- a) à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público dos Estados.
- b) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos Procuradores dos Estados.
- c) ao Ministério Público Federal e aos Procuradores dos Estados.
- d) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e às Defensorias Públicas dos Estados.
- e) às Defensorias Públicas da União e aos Advogados credenciados.

3. (Procurador da Assembleia Legislativa de SP/FCC/2010) A Advocacia-Geral da União:

- I. é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente.
- II. tem por competência, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- III. tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Congresso Nacional dentre os funcionários de carreira maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada.
- IV. tem por competência a execução da dívida ativa de natureza tributária da União.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

4. (Exame da OAB Unificado 2010.2 — FGV) Considerando que, nos termos dispostos no art. 133 da Constituição do Brasil, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo até mesmo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, é correto afirmar que:

- a) a imunidade profissional não pode sofrer restrições de qualquer natureza.

- b) nenhuma demanda judicial, qualquer que seja o órgão do Poder Judiciário pelo qual tramite, independentemente de sua natureza, objeto e partes envolvidas, pode receber a prestação jurisdicional se não houver atuação de advogado.
- c) a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho é assegurada nos termos da lei, não sendo vedadas, contudo, a busca e a apreensão judicialmente decretadas, por decisão motivada, desde que realizada na presença de representante da OAB, salvo se esta, devidamente notificada ou solicitada, não proceder à indicação.
- d) a prisão do advogado, por motivo de exercício da profissão, somente poderá ocorrer em flagrante, mesmo em caso de crime afiançável.

5. (Advogado — AGU — CESPE/UnB/2012) Acerca da AGU, julgue o item a seguir:

Incumbe à AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado, exercer a representação judicial e extrajudicial da União, assim como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito federal.

6. (Advogado — AGU — CESPE/UnB/2012) Acerca da AGU, julgue o item a seguir:

A CF estabelece expressamente que a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

7. (Agente Penitenciário — DEPEN — CESPE/UnB/2013) Com relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir:

No que toca à imunidade profissional do advogado, não constituem injúria ou difamação puníveis qualquer ato ou manifestação praticada no exercício de sua atividade. Entretanto, se, por exemplo, o advogado desacatar um agente penitenciário que age no exercício de sua função, o STF entende que não há imunidade, e pode ser instaurado processo-crime contra o causídico.

■ 12.7.3. Defensoria Pública

1. (Analista Administrativo MPU — CESPE/2010) Julgue o item a seguir, referente ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

A CF assegura autonomia funcional, administrativa e financeira às defensorias públicas estaduais, por meio das quais o Estado cumpre o seu dever constitucional de garantir às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à justiça.

2. (CESPE/UnB — DPU — 08.08.2004) Acerca da Defensoria Pública da União (DPU), do direito administrativo e do direito constitucional, julgue os itens a seguir.

191. O defensor público-geral da União, tal como o Procurador-Geral da República e os ministros do STF, somente pode ser nomeado após ter o seu nome aprovado pelo Senado Federal.
192. Considere a seguinte situação hipotética. Ronaldo, cidadão brasileiro pobre, necessita de assistência jurídica extrajudicial. Nessa situação, a DPU não pode prestar a referida assistência, porque os órgãos que compõem essa instituição voltam-se exclusivamente à prestação de assistência judicial.
193. Se a DPU firmasse convênio com a Defensoria Pública do Estado do Pará para que os defensores públicos estaduais atuassem em nome da DPU junto a determinados órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus de jurisdição, esse convênio seria nulo porque não podem ser delegadas, por via contratual, competências fixadas em lei.
194. Considere a seguinte situação hipotética. Em atenção ao pleito do governador de um estado, o presidente da República editou decreto determinando a remoção, de ofício, para a DPU nesse estado de cinco defensores públicos que exerciam suas funções no Distrito Federal, com o objetivo de possibilitar um melhor atendimento à população. Nessa situação, seria nulo o referido decreto presidencial de remoção.

3. (CESPE/UnB — DPU — 08.08.2004) Julgue os itens seguintes, relacionados à Defensoria Pública.

182. O defensor público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, sob pena de nulidade.
183. O benefício do prazo em dobro para recorrer é concedido aos defensores públicos, mas não se estende àqueles que fazem parte do serviço estatal de assistência judiciária.

4. (CESPE/UnB — DP São Paulo — 2006) Aos defensores públicos é vedado:

- a) filiar-se a partido político;
- b) exercer o magistério;
- c) fazer parte de sociedade comercial;
- d) integrar associação civil;
- e) exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais.

5. (CESPE/UnB — DP Aracaju — 2005) No que se refere à disciplina da defensoria

pública na Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir:

- 5.1 Conforme entendimento do STF, a constituição estadual pode ampliar as atribuições da defensoria pública dos estados, como, por exemplo, para a defesa de servidores públicos em razão do exercício de cargos públicos.
- 5.2 A disciplina sobre organização e funcionamento da defensoria pública no âmbito dos estados e do DF é matéria inserida na competência concorrente, de forma que compete à União legislar, por meio de lei complementar, sobre normas gerais, e aos estados e o DF, sobre normas específicas.
- 5.3 A atribuição dos defensores públicos não se estende à defesa dos necessitados em processos administrativos.

6. (Procurador do Ministério Público Especial de Contas — TCM/BA — FCC/2011) A Constituição da República assegura IGUALMENTE aos membros das carreiras de advocacia pública e defensoria pública

- a) estabilidade após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
- b) remuneração por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
- c) possibilidade de exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, observadas as condições estabelecidas em lei.
- d) autonomia funcional para exercer a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes da federação aos quais se vinculem.
- e) ingresso nas classes iniciais das carreiras mediante concurso público, de provas e títulos, com a participação da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases.

7. (Defensor Público/AM — Instituto Cidades/2011) O Defensor Público do Estado do Amazonas em exercício no Município de Parintins recebe em seu gabinete pais de crianças entre zero e cinco anos de idade, que não possuem condições de pagar advogado sem prejuízo do sustento de suas famílias, reclamando da insuficiência de vagas em creches mantidas pelo poder público municipal. Nesse caso, o Defensor Público:

- a) não deverá tomar qualquer providência, porque o aumento da oferta de vagas em creches é questão que envolve custos ao erário e, portanto, está no âmbito da

discrecionabilidade administrativa.

- b) não deverá tomar qualquer providência, porque, embora não haja ofensa ao princípio da reserva do possível, a Defensoria Pública não tem competência para o ajuizamento de ação civil pública, devendo apenas encaminhar os pais ao Ministério Público local para solucionar a questão.
- c) ajuizará ação judicial, visando a tornar efetivo o acesso e o atendimento em creches e unidades de pré-escola, em face do dever jurídico-social imposto ao Município pela Constituição Federal de 1988, mas não obterá êxito em última instância, por representar indevida ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas afetas ao Executivo.
- d) ajuizará ação judicial, visando a tornar efetivo o acesso e o atendimento em creches e unidades de pré-escola, em face do dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal de 1988 e pelo caráter de fundamentalidade de que se acha impregnado o direito à educação, de tal sorte a autorizar o Judiciário a proferir provimentos jurisdicionais que viabilizem a concreção dessa prerrogativa constitucional.
- e) irá sugerir a cada um dos pais presentes que impetrem mandado de segurança, individual ou em litisconsórcio ativo, com apoio no direito à educação infantil, pois esta é a única via judicial apropriada e a Defensoria Pública não está apta a utilizá-la.

8. (Defensor Público/TO — CESPE/UnB/2013) Consoante o disposto na CF e a jurisprudência do STF, assinale “certo” ou “errado” (adaptada — questão original com 5 alternativas):

O poder constituinte derivado não dispõe do juízo de abolição da Defensoria Pública por emenda constitucional, por ser a DP instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado.

9. (Analista de Informática — TCE/RO — CESPE/UnB/2013) A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item:

A CF autoriza expressamente a contratação temporária de advogados para o exercício das funções de defensor público, em situações excepcionais.

■ **12.7.4. Geral**

1. (MPT/2006) Quanto às funções essenciais à Justiça:

- I. as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que

deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição;

- II. os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, assegurando-se-lhes estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias;
- III. à Defensoria Pública incumbe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, assim considerados, pela Constituição Federal, os que comprovarem insuficiência de recursos.

Analisando-se as asserções acima, pode-se concluir que:

- a) todas estão corretas;
- b) todas estão incorretas;
- c) apenas a de número I está correta;
- d) apenas a de número III está incorreta;
- e) não respondida.

2. (TJ DF/2007) No trato das Funções Essenciais à Justiça, tal como preconizado na Constituição Federal de 1988, é incorreto afirmar:

- a) Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, de acordo com os limites legais;
- b) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas e serão estáveis após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias;
- c) Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
- d) A lei pode disciplinar a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações exarados no exercício da profissão.

3. (TJ MG EJEJF 2008) A Constituição da República estabelece as funções essenciais à Justiça e discrimina regras sobre o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública:

- a) O advogado, conquanto indispensável à administração da justiça, não possui inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão.
- b) A Defensoria Pública Estadual constitui órgão integralmente subordinado ao Poder Executivo e não lhe é assegurada autonomia alguma, quer funcional ou administrativa.
- c) A legitimação do Ministério Público para as ações civis mencionadas no texto constitucional e na lei impede a de terceiros.
- d) Ao Ministério Público compete, dentre outras funções institucionais, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar.

4. (Auditor Público Externo — TCE/RS — FMP-RS/ 2011) Sobre as funções essenciais à justiça na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) Não é constitucionalmente obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no concurso público de provas e títulos para ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União e das Defensorias Públicas da União e dos Estados.
- b) O Chefe da Advocacia-Geral da União é nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal.
- c) A partir da EC n. 45/2004, está constitucionalmente garantida à Defensoria Pública da União e às Defensorias Públicas Estaduais a autonomia funcional e administrativa.
- d) Os membros do Ministério Público nos Tribunais de Contas dos Estados são cedidos pelo Ministério Público Estadual, asseguradas as mesmas garantias constitucionais e observados os mesmos impedimentos aos membros do órgão de origem.
- e) Exige-se do bacharel em direito no mínimo três anos de atividade jurídica para o ingresso na carreira do Ministério Público, da Advocacia Pública, da União e dos Estados, e das Defensorias Públicas da União e dos Estados.

5. (Administrador — TJ/RR — CESPE/UnB/2012) Além da assistência jurídica integral e gratuita aos mais necessitados, a Defensoria Pública pode promover a defesa judicial dos servidores públicos processados civil e criminalmente em decorrência do regular exercício do cargo, desde que haja previsão expressa, nesse sentido, em lei estadual.

6. (Magistratura/MA — CESPE/UnB/2013) Consoante ao disposto na legislação e na jurisprudência, assinale a opção correta no que concerne às funções essenciais à justiça:

- a) A regra estabelecida na CF a respeito da indispensabilidade da intervenção do advogado não é absoluta, razão pela qual não é obrigatória a participação do advogado nas causas criminais dos juizados especiais.
- b) A defensoria pública não pode prestar assistência judiciária a servidor público processado, civil ou penalmente, por ato praticado em razão do exercício regular de suas funções.
- c) Não se aplica aos membros do MP que ingressaram na instituição após o advento da atual CF a denominada quarentena estabelecida para a magistratura, que consiste na vedação de exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastem antes de decorridos três anos de afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração.
- d) É inconstitucional regra estabelecida na constituição estadual segundo a qual a escolha do chefe da Procuradoria-Geral do Estado ou da Advocacia-Geral do Estado pelo Governador deva recair, necessariamente, sobre membro integrante da carreira, por se contrapor ao modelo federal, de observância obrigatória pelos Estados-membros da Federação.

■ GABARITO ■

■ 12.7.1. Ministério Público

1. “b”. Em relação à organização do Ministério Público da União, de fato, a Constituição dispõe ser hipótese de competência privativa do Presidente da República (art. 61, § 1.º, II, “d”). No entanto, o constituinte originário de 1988 previu exceção a esta regra, no art. 128, § 5.º, onde atribuiu competência, também, ao Procurador-Geral da República para dispor sobre a organização do Ministério Público da União. Assim, a questão poderia estar mais bem formulada referindo-se à competência concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República. No tocante à organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a CE/SP, em seu art. 23, § 2.º, “4”, confere iniciativa exclusiva ao Governador do Estado.

2. Não, por força do art. 129, § 2.º, que exige que as funções do Ministério Público só sejam

exercidas por integrantes da carreira e em decorrência do princípio do promotor natural, na medida em que, além de ser julgado por um julgador independente e pré-constituído (princípio do juiz natural), o acusado tem, também, o direito constitucional de ser acusado por um órgão independente do Estado, vedando-se a designação de promotores <i>ad hoc</i> (art. 129, I, c/c os arts. 129, § 2.º, e 5.º, LIII).
3. Os princípios institucionais do Ministério Público, segundo o art. 127, § 1.º, são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (<i>vide</i> parte teórica).
4. Decorridos 2 anos do efetivo exercício (estágio probatório), o membro do Ministério Público só poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado (art. 128, § 5.º, I, “a”). O art. 38, § 1.º, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) estabelece que o membro vitalício somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos casos de: <i>a</i>) prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado; <i>b</i>) exercício da advocacia; e <i>c</i>) abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores, na forma da lei orgânica.
5. O art. 128, II, “c”, da CF/88 veda a participação em sociedade comercial, na forma da lei. A Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), por seu turno, veda o exercício de comércio ou a participação de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Assim, poderá participar como cotista ou acionista.
6. <i>Vide</i> parte teórica.
7. A resposta encontra-se no art. 10, X, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), que atribui a competência ao Procurador-Geral de Justiça, que, inclusive, designará quem deverá officiar no feito.
8. “b”.
9. “d”. Dentre os órgãos acima, o Ministério Público só não participa do TSE (que é composto, de acordo com o art. 119 da CF/88, por 3 Ministros do STF, 2 do STJ e 2 advogados). Por outro lado, haverá membro do Ministério Público na composição do: <i>a</i>) STJ (art. 104, II); <i>b</i>) STM (art. 123, II); <i>c</i>) TST (art. 111, § 1.º, I); e <i>e</i>) TCU (art. 73, § 2.º, I, lembrando que, como já vimos, o Ministério Público que atua junto ao TCU, apesar de ter os mesmos direitos, vedações e forma

de investidura que o Ministério Público da União, não está vinculado a esta última carreira, mas ao próprio TCU).
10. “a”. De acordo com o art. 16, <i>caput</i> , da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), dentre Procuradores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução.
11. “a”. De acordo com o art. 15, VII, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).
12. “b”. As outras alternativas estão previstas expressamente na CF, como funções institucionais do MP, nos incisos V, I, VII e IX do art. 129, na sequência das alternativas propostas. O inciso IX do art. 129, em sua última parte, veda, expressamente, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, função esta não atribuída ao MP pela CF e, portanto, a resposta esperada pelo examinador.
13. “b”. Art. 129, IX, parte final. As outras funções institucionais estão previstas: a) inciso VI; c) inciso VII; d) inciso V; e) inciso VIII, todos do art. 129 da CF/88.
14. “d”.
15. “d”.
16. “certo”.
17. “e”.
18. “d”.
19. “c”.
20. “e”, conforme parte teórica.
21. “certo”. Art. 130-A, § 2.º, III.
■ 12.7.2. Advocacia
1. “c”. De acordo com o art. 133 da CF/88, observadas as regras do Estatuto da OAB, Lei n. 8.906/94. Entendemos que essa questão deveria ser demandada na prova de Ética.

2. “b”. Arts. 131, § 3.º, e 132.
3. “a”.
4. “c”.
5. “errado”. De acordo com o art. 131, <i>caput</i> , da CF/88, a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico apenas do Poder Executivo.
6. “certo”. Cf. art. 131, § 3.º.
7. “certo”, cf. <i>item 12.5.1</i> .
■ 12.7.3. Defensoria Pública
1. “certo”. Cf. art. 134, § 2.º.
2. 191. “certo”. De fato, os Ministros do STF e o PGR são nomeados pelo Presidente da República após a sua aprovação pela maioria absoluta do SF (arts. 101, parágrafo único, e 128, § 1.º, da CF/88). Em relação ao Defensor Público-Geral da União (que, a partir da LC n. 132/2009, passou a ser denominado Defensor Público-Geral Federal), o art. 6.º da LC n. 80/94 estabelece: “a Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríple formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado Federal”. 192. “Errado”. Conforme vimos e nos termos do art. 1.º da LC n. 80/94, “a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei”. 193. “Errado”, em razão de expressa previsão para o estabelecimento de convênio nos termos do art. 14, § 1.º, da LC n. 80/94, incluído pela LC n. 98/99. 194. “Certo”, nos termos do art. 79 da LC n. 80/94, na medida em que “os membros da

Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios são inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória, na forma desta Lei Complementar”.
3. 182. “Certo”. 183. “Errado”, já que, como visto, também se estende aos que fazem parte do serviço estatal.
4. “e”, cf. art. 134, § 1.º, da CF.
5. Item 5.1 — <i>errado</i>, nos termos da análise feita na parte teórica deste estudo (item 12.6.9.2); Item 5.2 — <i>errado</i>, nos termos do art. 134, § 1.º. Item 5.3 — <i>errado</i>, trata-se da prestação da assistência jurídica, integral e gratuita, que engloba tanto a assistência judiciária como a fora do processo judicial, bem como, portanto, o processo administrativo.
6. “b”.
7. “d”.
8. “certo”. Acabar com a Defensoria Pública por emenda seria pôr fim à instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que tem por incumbência, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Dessa forma, haveria afronta ao inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal, direito e garantia individual e, portanto, limite material à atuação do constituinte reformador.
9. “errado”. Conforme se observou, a Constituição explicita a figura do defensor público natural, a ser investido na carreira por concurso público.
■ 12.7.4. Geral
1. “a”.
2. “b”. Art. 132, parágrafo único, da CF/88.
3. “d”. Art. 129, VII, da CF/88.
4. “a”, na medida em que a exigência é apenas para os concursos de Procurador do Estado ou do DF (art. 132 e, por exclusão, os arts. 131, § 2.º, e 134, § 1.º). A <i>letra “b”</i> está errada, na

medida em que o AGU é de livre nomeação do Presidente da República, nos termos do art. 131, § 1.º. A *letra “c”* está errada, pois referida autonomia, conforme visto, é apenas para a defensoria pública estadual (art. 134, § 2.º). A EC n. 69/2012 estabeleceu autonomia para defensoria pública do Distrito Federal e a EC n. 74/2013 para a da União. A *letra “d”* está errada, na medida em que o MP junto ao TC deve ser entendido como um MP especial, não podendo haver o aproveitamento (art. 130 e parte teórica). A *letra “e”* está errada porque a quarentena de entrada só é exigida, explicitamente, para a carreira da magistratura e do MP.

5. “errado”. Cf. item 12.6.9.2.

6. “b”.

DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

■ 13.1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS — SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES¹

Destacam-se no tema da “defesa do Estado e das instituições democráticas” dois grupos: **a)** instrumentos (medidas excepcionais) para manter ou restabelecer a ordem nos momentos de anormalidades constitucionais, instituindo o **sistema constitucional de crises**, composto pelo **estado de defesa** e pelo **estado de sítio** (legalidade extraordinária); **b)** defesa do País ou sociedade, através das **Forças Armadas** e da **segurança pública**.

A **defesa do Estado** pode ser entendida como: **a)** defesa do território nacional contra eventuais invasões estrangeiras (arts. 34, II, e 137, II); **b)** defesa da soberania nacional (art. 91); **c)** defesa da Pátria (art. 142).²

A **defesa das instituições democráticas** caracteriza-se como o equilíbrio da ordem constitucional, não havendo preponderância de um grupo sobre outro, mas, em realidade, o **equilíbrio entre os grupos de poder**. Se a competição entre os grupos sociais extrapola os limites constitucionais, teremos o que a doutrina denomina *situação de crise*.³

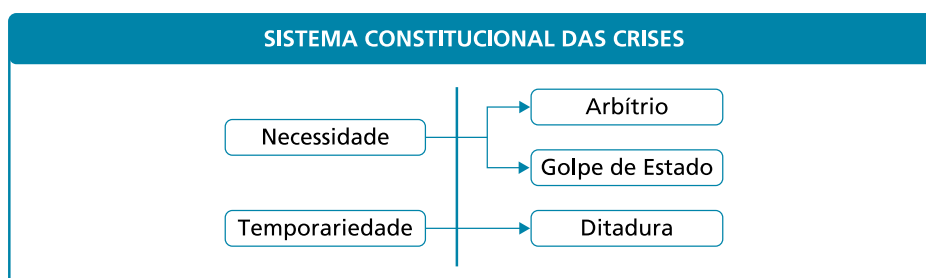
Assim, ocorrendo qualquer violação da normalidade constitucional, surge o denominado **sistema constitucional das crises**, definido por Aricê Amaral Santos como “... o conjunto ordenado de normas constitucionais que,

informadas pelos princípios da **necessidade** e da **temporariedade**, têm por objeto as situações de crises e por finalidade a **manutença** ou o **restabelecimento da normalidade constitucional**".⁴

José Afonso da Silva observa que o sistema constitucional das crises fixa "... normas que visam à estabilização e à defesa da Constituição contra processos violentos de mudança ou perturbação da ordem constitucional, mas também à defesa do Estado quando a situação crítica derive de guerra externa. Então, a legalidade normal é substituída por uma **legalidade extraordinária**, que define e rege o estado de exceção".⁵

Diante das crises, portanto, existem mecanismos constitucionais para o restabelecimento da normalidade, quais sejam, a possibilidade de decretação do estado de defesa, do estado de sítio e o papel das Forças Armadas e das forças de segurança pública (Título V da CF/88).

Referidos mecanismos devem, contudo, como apontou Aricê Amaral Santos, respeitar o princípio da **necessidade**, sob pena de configurar **arbítrio** e verdadeiro **golpe de estado**, bem como o princípio da **temporariedade**, sob pena de configurar verdadeira **ditadura**.



Essas situações de abuso, arbítrio, golpe, ditadura podem ser verificadas no constitucionalismo pátrio, por exemplo, durante o "Estado Novo" de Getúlio Vargas (Carta de 1937), no governo da ditadura militar de 1964 até o seu fim com a Constituição de 1988, e, durante o período ditatorial, pela utilização do AI-5, momentos em que se decretou estado de sítio e de guerra sem qualquer observância aos princípios da necessidade e temporariedade.

■ 13.2. ESTADO DE DEFESA

■ 13.2.1. Hipóteses de decretação do estado de defesa

As hipóteses em que se poderá decretar o estado de defesa estão, de forma taxativa, previstas no art. 136, *caput*, da CF/88, quais sejam: para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a **ordem pública** ou a **paz social ameaçadas** por grave e iminente **instabilidade institucional** ou atingidas por **calamidades de grandes proporções na natureza**.

■ 13.2.2. Procedimento e regras gerais

■ **Titularidade:** o Presidente da República (art. 84, IX, c/c o art. 136), mediante **decreto**, pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa.

■ **Conselho da República e Defesa Nacional:** como órgãos de consulta, são previamente ouvidos, porém suas opiniões **não** possuem caráter vinculativo, ou seja, o Presidente da República, mesmo diante de um parecer opinando pela desnecessidade de decretação, poderá decretar o estado de defesa.

■ **O decreto que instituir o estado de defesa deverá determinar:** *a)* o tempo de duração; *b)* a área a ser abrangida (**locais restritos e determinados**); *c)* as medidas coercitivas que devem vigorar durante a sua vigência.

■ **Tempo de duração:** máximo de **30 dias** prorrogados por mais **30 dias**, uma única vez.

■ **Medidas coercitivas:** *a)* restrições (não supressão) aos direitos de **reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica** e à garantia prevista no art. 5.º, LXI, ou seja, **prisão** somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente; *b)* ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

■ **Prisão por crime contra o Estado:** como exceção ao art. 5.º, LXI, a

prisão poderá ser determinada pelo executor da medida (não pela autoridade judicial competente). O juiz competente, imediatamente comunicado, poderá relaxá-la. Tal comunicação deverá vir acompanhada do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Referida ordem de prisão não poderá ser superior a **10 dias**, facultando-se ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial.

■ **Incomunicabilidade do preso:** é vedada.

■ 13.2.3. Controle exercido sobre a decretação do estado de defesa ou sua prorrogação

■ **Controle político imediato:** nos termos do art. 136, §§ 4.º-7.º, será realizado pelo **Congresso Nacional**. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá pela **maioria absoluta** de seus membros. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado pelo **Presidente do Senado Federal** (art. 57, § 6.º, I, da CF/88), **extraordinariamente**, no prazo de 5 dias, e deverá apreciar o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Se o Congresso rejeitar o decreto, o estado de defesa cessará **imediatamente**.

■ **Controle político concomitante:** nos termos do art. 140, a Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de 5 de seus membros para **acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa**.

■ **Controle político sucessivo (ou a posteriori):** nos termos do art. 141, parágrafo único, logo que cesse o estado de defesa, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

Prestadas as informações e não aceitas pelo Congresso Nacional, entende José Afonso da Silva parecer ficar “... caracterizado algum crime de

responsabilidade do presidente, especialmente o atentado a direitos individuais — pelo que pode ser ele submetido ao respectivo processo, previsto no art. 86 e regulado na Lei 1.079/50”.[6](#)

■ **Controle jurisdicional concomitante:** durante a decretação do estado de defesa, conforme o art. 136, § 3.º, haverá controle pelo Judiciário da prisão efetivada pelo executor da medida. A prisão ou detenção de qualquer pessoa, também, não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

A nosso ver, também, qualquer lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5.º, XXXV, não poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário, claro, observados os limites constitucionais das permitidas restrições a direitos (art. 136, § 1.º). Parece, assim, que o Judiciário poderá reprimir abusos e ilegalidades cometidos durante o estado de crise constitucional por meio, por exemplo, do mandado de segurança, do *habeas corpus* ou de qualquer outra medida jurisdicional cabível.

No entanto, como anota Alexandre de Moraes, lembrando Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em relação “... à análise do mérito *discrecionário* do Poder Executivo (no caso do Estado de Defesa) e desse juntamente com o Poder Legislativo (no caso do Estado de Sítio), a doutrina dominante entende **impossível**, por parte do Poder Judiciário, a análise da conveniência e oportunidade política para a decretação”.[7](#)

■ **Controle jurisdicional sucessivo (ou a posteriori):** consoante o art. 141, *caput*, cessado o estado de defesa, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da **responsabilidade** pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

■ 13.3. ESTADO DE SÍTIO

■ 13.3.1. Hipóteses de decretação do estado de sítio

As hipóteses em que poderá ser decretado o estado de sítio estão, de forma taxativa, previstas no art. 137, *caput*, da CF/88:

comoção grave de repercussão **nacional** (se fosse de repercussão **restrita** e em **local determinado**, seria hipótese, primeiro, de decretação de estado de defesa);

ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa (portanto, pressupõe-se situação de maior gravidade);

declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

■ 13.3.2. Procedimento e abrangência

Assim como no estado de defesa, quem **decreta** o estado de sítio é o **Presidente da República**, após prévia oitiva do Conselho da República e de Defesa Nacional (pareceres não vinculativos).

No entanto, para a decretação do estado de sítio ou sua prorrogação, ao contrário do que ocorre com o estado de defesa, deverá haver, relatando os motivos determinantes do pedido, **prévia** solicitação pelo Presidente da República de autorização do Congresso Nacional, que se manifestará pela **maioria absoluta** de seus membros.

O controle político prévio, se negativo, será vinculante, e o Presidente da República não poderá decretar o estado de sítio por aquele motivo, sob pena de responsabilidade. Por outro lado, se o Congresso Nacional autorizar, com discricionariedade política, o Presidente da República poderá ou não decretar o estado de sítio.

Neste último caso, o **decreto do estado de sítio** indicará sua **duração**, as **normas necessárias a sua execução** e **as garantias constitucionais que ficarão suspensas**, e, **depois de publicado**, o Presidente da República designará o **executor das medidas específicas** e as **áreas abrangidas** (art. 138, *caput*).

Dessa forma, a **designação das áreas abrangidas** dar-se-á **depois de publicado o decreto do estado de sítio**, não necessariamente tendo de

abranger, portanto, toda a área geográfica do território nacional, apesar de se tratar de comoção grave de **repercussão nacional**.

A **duração** do estado de sítio, no caso de comoção grave de repercussão nacional ou da ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa (art. 137, I), não poderá ser superior a **30 dias**, podendo ser prorrogada, sucessivamente (não há limites), enquanto perdurar a situação de anormalidade, sendo que cada prorrogação também não poderá ser superior a **30 dias**.

No caso de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira (art. 137, II), enquanto perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.

■ 13.3.3. Medidas coercitivas

Nas hipóteses do art. 137, I (comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa), só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes **medidas coercitivas** (art. 139, I a VII):

- obrigação de permanência em localidade determinada;
- detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
- restrições (não supressões) relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei (desde que liberada pela respectiva Mesa, não se inclui a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas);
- suspensão da liberdade de reunião;
- busca e apreensão em domicílio;
- intervenção nas empresas de serviços públicos;
- requisição de bens.

Em relação à decretação de estado de sítio na hipótese do art. 137, II, qual seja, no caso de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde

que: **a)** tenham sido observados os princípios da **necessidade** e da **temporariedade** (enquanto durar a guerra ou resposta a agressão armada estrangeira); **b)** tenha havido prévia autorização por parte do Congresso Nacional; **c)** nos termos do art. 138, *caput*, tenham sido indicadas no decreto do estado de sítio a sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. [8](#)

■ 13.3.4. Controle exercido sobre a decretação do estado de sítio

■ **Controle político prévio:** tendo em vista a maior gravidade do estado de sítio, o controle realizado pelo **Congresso Nacional** será **prévio**, ou seja, o Presidente da República, para a sua decretação ou prorrogação, depende de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional. Se o Congresso rejeitar o pedido, o Presidente da República, agora vinculado, não poderá decretar o estado de sítio. Se o fizer, sem dúvida, cometerá crime de responsabilidade. Estando o Congresso Nacional em recesso, haverá convocação extraordinária, pelo **Presidente do Senado Federal** (art. 57, § 6.º, I, da CF/88). Decretado o estado de sítio, nos termos do art. 138, § 3.º, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

■ **Controle político concomitante:** a Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de 5 de seus membros para **acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de sítio** (art. 140).

■ **Controle político sucessivo (ou a posteriori):** logo que cesse o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas (art. 141, parágrafo único).

Conforme visto para o estado de defesa, prestadas as informações e não aceitas pelo Congresso Nacional, parece ficar caracterizada a prática do crime de responsabilidade.

■ **Controle jurisdicional concomitante:** qualquer lesão ou ameaça a direito, abuso ou excesso de poder durante a sua execução não poderão deixar de ser apreciados pelo Poder Judiciário, observados, é claro, os limites constitucionais da “legalidade extraordinária”, seja por via do mandado de segurança, seja por meio de *habeas corpus* ou de qualquer outro remédio.

Tal como anotado para o estado de defesa, o juízo de conveniência para a decretação do estado de sítio cabe ao Presidente da República.

■ **Controle jurisdicional sucessivo (ou a posteriori):** cessado o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da **responsabilidade** pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes (art. 141, *caput*).

■ 13.4. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS ESTADOS DE DEFESA E DE SÍTIO

Em se tratando de **medidas excepcionais**, somente poderão ser adotadas dentro dos limites constitucionais, nas hipóteses expressamente previstas, enfim, somente durante a chamada **crise constitucional**.⁹ “Em outras palavras (concluem Araujo e Nunes Júnior), se medidas de exceção forem aplicadas em tempos de normalidade democrática, a Constituição estará sendo violada, configurando-se autêntico golpe de estado”.¹⁰

Decretado o estado de defesa ou o estado de sítio, haverá o controle político concomitante (art. 140 da CF/88).

Por razões óbvias, cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

Dada a gravidade das medidas (por restringirem direitos constitucionais), logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, o Presidente da República terá de prestar contas, respondendo por abusos e arbítrios.

■ 13.5. QUADRO COMPARATIVO ENTRE O ESTADO DE DEFESA E O ESTADO DE SÍTIO

	ESTADO DE DEFESA (ART. 136)	ESTADO DE SÍTIO (ART. 137, I)	ESTADO DE SÍTIO (ART. 137, II)
HIPÓTESES DE CABIMENTO	- ordem pública ou paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional - ordem pública ou paz social atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza	- comoção grave de repercussão nacional - ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa	- declaração de estado de guerra - resposta a agressão armada estrangeira
ÁREAS ABRANGIDAS	locais restritos e determinados	âmbito nacional — especificado após a decretação (art. 138, <i>caput</i>)	âmbito nacional — especificado após a decretação (art. 138, <i>caput</i>)
DECRETAÇÃO	exclusivamente pelo Presidente da República (art. 84, IX)	<i>idem</i>	<i>idem</i>
ÓRGÃOS DE	- Conselho da República (art. 90, I) - Conselho de Defesa Nacional (art.		

PRESIDENTE DA REPÚBLICA	91, II) ■ os pareceres não são vinculativos ■ a oitiva dos Conselhos é prévia	■ <i>idem</i>	■ <i>idem</i>
CONTEÚDO DO DECRETO INTERVENTIVO	■ tempo de sua duração ■ áreas a serem abrangidas (indicadas já no decreto) ■ medidas coercitivas a vigorarem, nos termos e limites da lei	■ tempo de sua duração ■ as normas necessárias a sua execução ■ as garantias constitucionais que ficarão suspensas, só podendo ser tomadas as medidas previstas taxativamente no art. 139, I-VII ■ depois de publicado o decreto, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas	■ tempo de sua duração ■ as normas necessárias a sua execução ■ as garantias constitucionais que ficarão suspensas, em tese, qualquer garantia, desde que sejam respeitados os princípios da necessidade e da temporariedade, bem como os limites constitucionais ■ depois de publicado o decreto, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as

		áreas abrangidas	áreas abrangidas
TEMPO DE DURAÇÃO	■ máximo de 30 dias, podendo ser prorrogado por novo período de no máximo 30 dias uma única vez (art. 136, § 2.º)	■ máximo de 30 dias, podendo ser prorrogado por novos períodos de até 30 dias, quantas vezes se mostrar necessário ■ a cada nova prorrogação, todo o procedimento deverá ser observado, como se fosse um novo decreto	■ o tempo necessário da guerra ■ o tempo necessário para repelir agressão armada estrangeira
	■ diante da hipótese	■ estando diante da hipótese de cabimento, o Presidente da República ouve os Conselhos (parecer não vinculativo) e solicita prévia autorização do CN ■ ao solicitar autorização para	

PROCEDIMENTO	Presidente da República ouve os Conselhos (parecer não vinculativo) e, com discricionariade política, decreta ou não o estado de defesa para posterior controle político do Congresso Nacional	de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o CN decidir por maioria absoluta ■ autorizado, com discricionariade política, o Presidente poderá decretar ou não o estado de sítio ■ persistindo as situações de anormalidade, todo o procedimento deverá ser repetido	■ <i>idem</i> procedimento do art. 137, I (estado de sítio)
		■ art. 139, I a VII ■ obrigação de permanência em localidade determinada (art. 5.º, XV)	

**MEDIDAS
COERCITIVAS —
RESTRIÇÕES A
DIREITOS E
GARANTIAS**

■ restrições (não supressão — art. 136, § 1.º, I) aos direitos de reunião (art. 5.º, XVI); sigilo de correspondência (art. 5.º, XII); sigilo de comunicação telegráfica e telefônica (art. 5.º, XII)

■ ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes (art. 136, § 1.º, II)

■ restrição à garantia prevista no art. 5.º, LXI, ou seja, prisão somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, já que poderá haver prisão

■ detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns (art. 5.º, LXI)

■ restrições relativas às seguintes inviolabilidades:

a) da correspondência (art. 5.º, XII)

b) ao sigilo das comunicações (art. 5.º, XII, — *exceto* a difusão de pronunciamentos parlamentares — parágrafo único do art. 139)

c) à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei (art. 220 — *exceto* a difusão de

■ em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde que: a) tenham sido observados os princípios da necessidade e da temporariedade (enquanto durar a guerra ou resposta a agressão armada estrangeira); b) tenha havido prévia autorização por parte do Congresso Nacional; c) nos termos do art. 138, *caput*, tenham sido indicadas, no decreto do estado de sítio, a sua duração, as normas necessárias a sua

	Estado determinada pelo executor da medida (art. 136, § 3.º, I-IV) ■ a incomunicabilidade do preso é vedada	pronunciamentos parlamentares — parágrafo único do art. 139) d) suspensão da liberdade de reunião (art. 5.º, XVI) e) busca e apreensão em domicílio (art. 5.º, XI) f) intervenção nas empresas de serviços públicos g) requisição de bens (art. 5.º, XXV)	garantias constitucionais que ficarão suspensas
	■ imediatos: logo após a decretação do estado de defesa ou sua prorrogação (art. 136, §§ 4.º a 7.º) ■ concomitantes: nos termos do art. 140, por Comissão do CN — durante a vigência do estado de anormalidade ■ sucessivos (ou a posteriori): nos	■ prévios: o Presidente da República, para a decretação, depende de prévia e expressa autorização do	

CONTROLE POLÍTICO	<i>posteriori</i>): nos termos do art. 141, parágrafo único, logo que cesse o estado de defesa, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, que apreciará sua legalidade e constitucionalidade, podendo, em caso de abuso, ocorrer a prática de crime de responsabilidade	Congresso Nacional ■ <i>concomitante</i>: <i>idem</i> estado de defesa (art. 140) ■ <i>sucessivo (ou a posteriori)</i>: <i>idem</i> estado de defesa (art. 141, parágrafo único)	■ <i>Idem</i> controle indicado para o estado de sítio (art. 137, I)
	■ <i>concomitante</i>: durante a decretação do estado de defesa, nos termos do art. 136, § 3.º, haverá controle, pelo Judiciário, da prisão efetivada pelo executor da medida. Outrossim, qualquer lesão ou ameaça a direito não poderá deixar de ser	■ <i>concomitante</i>: qualquer lesão ou ameaça a direito, abuso ou excesso de poder durante a sua execução não	

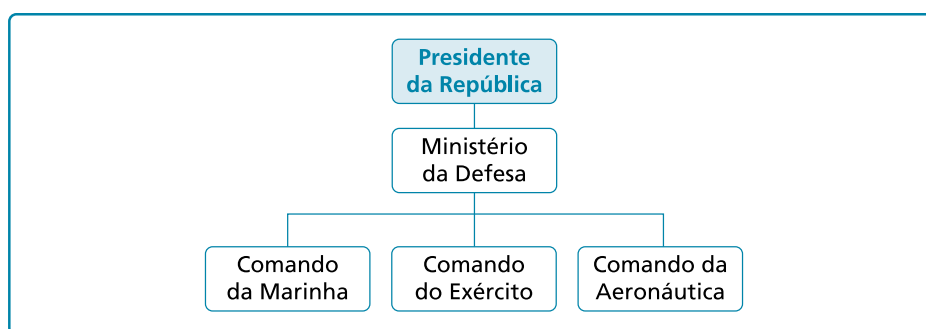
CONTROLE JURÍDICO	apreciada pelo Poder Judiciário (art. 5.º, XXXV), observados, é claro, os limites constitucionais (art. 136, § 1.º). Possibilidade de impetração de mandado de segurança, <i>habeas corpus</i> ou qualquer outra medida jurisdicional cabível ■ sucessivo (ou a posteriori): nos termos do art. 141, <i>caput</i>, cessado o estado de defesa, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes	poderão deixar de ser apreciados pelo Poder Judiciário, observados, é claro, os limites constitucionais da “legalidade extraordinária”, seja por via do mandado de segurança, seja por meio do <i>habeas corpus</i>, ou de qualquer outro remédio ■ sucessivo (ou a posteriori): <i>idem</i> estado de defesa (art. 141, <i>caput</i>)	■ <i>idem</i>
FUNCIONAMENTO DO CN	■ o CN deverá continuar funcionando enquanto vigorar o	■ o CN permanecerá em funcionamento até o término das medidas	■ <i>idem</i> estado de sítio — art. 137, I (art. 138, § 3.º)

	estado de defesa (art. 136, § 6.º)	medidas coercitivas (art. 138, § 3.º)	(art. 138, § 3.º)
VIOLAÇÃO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	possibilidade de se configurar crime de responsabilidade (art. 85 da CF), sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, além de responsabilidade civil, penal e administrativa	<i>idem</i>	<i>idem</i>
IMUNIDADES PARLAMENTARES	subsistirão, não havendo previsão de suspensão (art. 58, § 3.º)	subsistirão, podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do CN, que sejam incompatíveis com a execução da medida (art. 53, § 8.º)	<i>Idem</i> (situação prevista: estado de sítio — art. 137, I)

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CN	■ Presidente do SF (art. 57, § 6.º, I)	■ <i>idem</i>	■ <i>idem</i>
--	--	---------------	---------------

■ 13.6. FORÇAS ARMADAS

■ 13.6.1. Regras gerais



A **Marinha**, o **Exército** e a **Aeronáutica** constituem as **Forças Armadas**, sendo consideradas instituições nacionais permanentes e regulares, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [11](#)

As Forças Armadas organizam-se com base na **hierarquia** e na **disciplina**, sob a autoridade e comando supremos do **Presidente da República**, que tem por atribuições nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos (art. 84, XIII, na redação determinada pela EC n. 23, de 02.09.1999).

De acordo com o art. 5.º, *caput*, e § 1.º, da LC n. 97/99, os cargos de Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativos de oficiais-generais do último posto da respectiva Força, sendo assegurada aos referidos Comandantes **precedência hierárquica** sobre os demais oficiais-generais das três Forças Armadas.

Assim, os superiores hierárquicos e o Presidente da República, como **chefe**

gerais das três Forças Armadas.

Assim, os superiores hierárquicos e o Presidente da República, como **chefe maior**, com base na **hierarquia** e na **disciplina**, poderão aplicar sanções disciplinares de natureza administrativa.

Conforme escrevemos no *capítulo 11*, a **hierarquia** e a **disciplina** são a base institucional das **Forças Armadas**, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

A **hierarquia militar**¹² é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por **postos** ou **graduações** e, dentro de um mesmo posto ou graduação, pela **antiguidade** (no posto ou na graduação):

■ **posto**: é o grau hierárquico do **oficial**, conferido por ato do Presidente da República ou do Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica e confirmado em Carta Patente;

graduação: é o grau hierárquico da **praça**, conferido pela autoridade militar competente.

Por sua vez, a **disciplina** é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

Os membros das Forças Armadas, conforme estabelece o art. 142, § 3.º, são denominados **militares**, aplicando-se-lhes, além das regras que vierem previstas em lei, as seguintes disposições (incisos I a X, com alguns destaques apresentados nos itens seguintes):¹³

■ as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;

■ o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, **ressalvada a hipótese prevista no art. 37, XVI, “c”**, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei **(EC n. 77/2014)**;

■ ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

■ o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

■ o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

■ o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

■ aplica-se aos militares o disposto no art. 7.º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, **bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, XVI, “c” (EC n. 77/2014);**[14](#)

■ a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

■ 13.6.2. Novidades introduzidas pela EC n. 77/2014

Conforme se observa acima, a **EC n. 77/2014** alterou os incisos II, III e VIII

do § 3.º do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos **profissionais de saúde das Forças Armadas** a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, XVI, “c”.

Referida emenda vem corrigir a distorção estabelecida pela EC n. 18/98, que proibiu a acumulação de cargos por parte desses profissionais.

Assim, a EC n. 77/2014, ao permitir que os profissionais de saúde das Forças Armadas acumulem cargos na forma do **art. 37, XVI, “c”**, resgata a **isonomia** outrora existente nesse ponto da acumulação de cargos entre os servidores civis e militares e, acima de tudo, **evita** que esses profissionais **abandonem** as Forças Armadas em busca de melhores condições.

Como bem ficou assinalado no *Parecer n. 736/2013-CCJ*, “ante a dificuldade de prover remuneração equiparada à ofertada pela iniciativa privada, que inclusive admite a multiplicidade de vínculos empregatícios, temos que a proposta em apreço servirá para compensar tal defasagem e colaborará para **manter** nos quadros das Forças Armadas profissionais de escol, que nelas ingressam por **rigorosa seleção** e se dedicam de **forma sacerdotal** ao serviço da Pátria”.

■ 13.6.3. *Habeas corpus* e punições disciplinares militares

Caracterizando-se exceção expressa ao art. 5.º, LXVIII, com base no **princípio da hierarquia**, não caberá *habeas corpus* em relação a eventuais punições disciplinares militares (art. 142, § 2.º), vedação essa permitida, visto que introduzida pelo poder constituinte originário, que, como já referimos, **do ponto de vista jurídico**, é incondicionado, ilimitado e soberano na tomada de suas decisões, podendo, inclusive, trazer exceções às regras gerais.

Cabe observar, contudo, seguindo a jurisprudência do STF, a possibilidade de impetração de *habeas corpus* para a análise, pelo Judiciário, dos **pressupostos de legalidade** (hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente — HC 70.648, Moreira Alves), excluídas as questões do mérito da sanção administrativa (cf., por exemplo, RE

338.840-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 19.08.2003).

Nesse sentido: “A **legalidade** da imposição de punição constritiva da liberdade, em procedimento administrativo castrense, pode ser discutida por meio de *habeas corpus*. Precedentes” (RHC 88.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.04.2007, *DJ* de 27.04.2007).

■ 13.6.4. Serviço militar obrigatório

A **prestação do serviço militar** é **obrigatória**,¹⁵ ficando as mulheres e os eclesiásticos isentos de tal compulsoriedade em tempos de paz, sujeitando-se, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Apesar de obrigatória, alegando-se imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política (**direito de escusa de consciência**), às Forças Armadas competirá, na forma da lei, atribuir serviço alternativo em tempo de **paz** (art. 5.º, VIII, c/c o art. 143, §§ 1.º e 2.º).¹⁶

Havendo recusa da prestação alternativa nos termos da Lei n. 8.239/91, ter-se-á por sanção a declaração da **perda**¹⁷ **dos direitos políticos** (art. 15, IV, da CF/88).

■ 13.6.5. Leis de iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, I e II, “f”)

Conforme já estudado, as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas,¹⁸ bem como as que disponham sobre os seus militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para reserva, serão de **iniciativa privativa (exclusiva)** do Presidente da República.¹⁹

■ 13.6.6. As praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber abaixo do salário mínimo?

Nos termos do art. 142, § 3.º, VIII, aplica-se aos militares o disposto no art. 7.º, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com **prevalência da atividade militar**, no art. 37, XVI, “c” (**EC n. 77/2014**).

Não houve a previsão explícita da garantia do salário mínimo, constante do art. 7.º, IV e VII.

Diante dessa situação, o STF teve de enfrentar a constitucionalidade ou não do art. 18, § 2.º, da **MP n. 2.215-10**, de 31.08.2001 (com vigência determinada pelo art. 2.º da EC n. 32/2001), que exclui da garantia do salário mínimo as praças prestadoras de serviço militar inicial e as praças especiais, exceto o Guarda-Marinha e o Aspirante-a-Oficial.

Em diversos julgados, o STF apontou as particularidades do regime dos militares: “Constitucional. Serviço militar obrigatório. Soldo. Valor inferior ao salário mínimo. Violação aos arts. 1.º, III, 5.º, *caput*, e 7.º, IV, da CF. Inocorrência. RE desprovido. A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. **O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios**. Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um **múnus público** relacionado com a defesa da soberania da pátria. A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas” (RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.04.2008, *DJE* de 27.06.2008. Também: RE 551.453, RE 551.608, RE 551.713, RE 551.778, RE 555.897, RE 556.233, RE 556.235, RE 557.542, RE 557.606, RE 557.717, RE 558.279).

Nesse sentido, o STF editou a **Súmula Vinculante 6/2008**, com o seguinte teor: “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”.

■ 13.6.7. Editais de concurso podem estabelecer limite de idade para o

ingresso nas Forças Armadas?

De acordo com o inciso X do § 3.º do art. 142 da CF/88, a **lei** disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os **limites de idade**, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Referido inciso ainda não foi regulamentado durante a vigência do texto de 1988. Aponta-se que a Lei n. 6.880/80 — *Estatuto dos Militares* — teria sido recepcionada para tratar da matéria.

Contudo, alguns dispositivos do mencionado *Estatuto* foram questionados perante a CF/88 e, assim, discutida a recepção, dentre eles, do art. 10, que tem a seguinte redação: “o ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos **regulamentos** da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”.

Tendo em vista a falta de regulamentação específica por meio de lei, os **Editais** de concurso (regulamentos) sempre definiram regras para o ingresso nas Forças Armadas, inclusive o limite de idade.

O tema foi discutido no STF em razão da interposição do **RE 600.885** pela União, que contestou decisão do TRF 4 que entendeu como flagrantemente inconstitucional regra de edital de concurso que limitou em 24 anos a idade para ingresso nas Forças Armadas.

O STF, na linha do voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, definiu que a fixação do limite de idade tem de ser por **lei**, em sentido formal, nos exatos termos da literalidade do art. 142, § 3.º, X, da CF/88, não se admitindo a definição dos preceitos por regulamento, como são os *editais de concursos*.

Todavia, na linha da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, como já se havia passado mais de 20 anos, buscando evitar a insegurança jurídica, especialmente diante de vários concursos que já tinham sido realizados, admitiram-se a recepção do art. 10 da Lei n. 6.880/80 (com a sua alusão aos

especialmente diante de vários concursos que já tinham sido realizados, admitiram-se a recepção do art. 10 da Lei n. 6.880/80 (com a sua alusão aos Editais e demais atos administrativos) e a sua manutenção no ordenamento até **31.12.2011**, fazendo-se “apelo” para que o Congresso legislasse, modulando-se, assim, *pro futuro*, os efeitos da não recepção. Vejamos:

“EMENTA: (...). O art. 142, § 3.º, X, da Constituição da República é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: **referência constitucional taxativa ao critério de idade**. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. **Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/80**. O princípio da **segurança jurídica** impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, **modulem-se os efeitos da não recepção**: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei 6.880/80 até 31.12.2011” (**RE 600.885**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.02.2011, Plenário, *DJE* de 1.º.07.2011, com repercussão geral).

Em razão de **novo pedido**, o STF prorrogou a modulação dos efeitos da declaração de não recepção até **31.12.2012**, sem admitir, porém, nova postergação. Dessa forma, a partir de **1.º.01.2013**, a fixação de **limite de idade** deverá ser, necessariamente, por **lei em sentido formal**, não se admitindo nenhuma restrição por meio dos editais de concursos (**legalidade específica**).

Finalmente, foram acolhidos *embargos de declaração* interpostos para deixar expresso que a modulação da declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 **não alcança** os candidatos que obtiveram provimento jurisdicional para continuar no concurso, mesmo com idade acima dos limites previstos nos editais e regulamentos. Ou seja, aqueles que conseguiram, judicialmente, afastar as limitações de idade estabelecidas nos regulamentos estão assegurados (**RE**

■ 13.6.8. “Princípio da insignificância” e crimes militares: o caso concreto de posse de reduzida quantidade de substância entorpecente. Princípio da especialidade. Afastamento da nova Lei de Drogas

O **princípio da insignificância** ou **delito de bagatela** vem sendo discutido nos Tribunais, devendo ser aprofundado nos livros de *direito penal*.

Partindo da ideia de **intervenção mínima do Estado em matéria penal**, funciona como **fator de descaracterização material da tipicidade penal** e vem sendo aceito pelo **STF** em diversas situações (com outras tantas exclusões), podendo ser resumido os seus principais **vetores** na seguinte formulação de lavra do Min. Celso de Mello:

“EMENTA: (...) O **princípio da insignificância** — que deve ser analisado em conexão com os **postulados da fragmentariedade** e da **intervenção mínima do Estado em matéria penal** — tem o sentido de **excluir** ou de **afastar** a própria **tipicidade penal**, examinada na perspectiva de seu **caráter material**.” Tal postulado “... considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos **vetores**, tais como:

- mínima ofensividade da conduta do agente;
- nenhuma periculosidade social da ação;
- reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
- inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

Ainda, continua Celso de Mello, o **princípio da insignificância** “... apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a **intervenção mínima do Poder Público**. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘*DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR*’. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado

de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de **condutas** que produzam **resultado cujo desvalor** — por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes — **não** represente, por isso mesmo, **prejuízo importante**, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social...” (HC 84.687, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.10.2004, 2.^a Turma, DJ de 27.10.2006).

Pois bem, resta saber se a posse de quantidade reduzida de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, no caso analisado, de 0,1 g de maconha, permite seja adotada a tese da bagatela.

Muito embora existam diversos precedentes no sentido de se aplicar o princípio da insignificância aos crimes militares (HC 87.478, HC 92.634, RHC 89.624, HC 93.822 etc.), o STF firmou **novo** entendimento pela sua **não aplicabilidade**, fazendo prevalecer a regra contida no art. 290 do CPM.

Dessa forma, no embate entre a regra específica do Código Penal Militar e a previsão mais branda do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (*Nova Lei de Drogas*), entendeu o STF prevalecer a primeira, diante do **princípio da especialidade**.

ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR	ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
■ “Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:	■ “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I — advertência sobre os efeitos das drogas;

Pena — reclusão, até cinco anos.”	II — prestação de serviços à comunidade; III — medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”
-----------------------------------	--

A decisão foi apertada — por 6 x 4 —, no julgamento do **HC 103.684/DF** (Rel. Min. Ayres Britto, j. 21.10.2010, Plenário, *DJE* de 13.04.2011), no qual se discutia o caso de um **militar** surpreendido com pequena quantidade de maconha no *Hospital Geral de Brasília* (HGB), que é um estabelecimento militar.

De modo geral, assentou-se que a prática da conduta prevista no citado art. 290 do CPM “... **ofenderia** as **instituições militares**, a **operacionalidade** das **Forças Armadas**, além de violar os **princípios da hierarquia** e da **disciplina** na própria interpretação do tipo penal. Asseverou-se que a circunstância de a Lei n. 11.343/2006 ter atenuado o rigor na disciplina relacionada ao usuário de substância entorpecente não repercutiria no âmbito de consideração do art. 290 do CPM, **não havendo que se cogitar de violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana**. Salientou-se, ademais, que lei posterior apenas revoga anterior quando expressamente o declare, seja com ela incompatível, ou regule inteiramente a matéria por ela tratada. Concluiu-se não incidir qualquer uma das hipóteses à situação em tela, já que **o art. 290 do CPM seria norma especial**. Em seguida, reputou-se **inaplicável**, no âmbito do tipo previsto no art. 290 do CPM o **princípio da insignificância**. No ponto, após discorrer que o referido postulado tem como vetores **a mínima ofensividade da conduta do agente**, a **nenhuma periculosidade social da ação**, o **reduzido grau de reprovabilidade do comportamento** e a **inexpressividade da lesão jurídica provocada**, concluiu-se que o entorpecente no interior das organizações militares assumiria enorme **gravidade**, em face do **perigo** que acarreta, uma vez que seria utilizado, no serviço, armamento de alto poder ofensivo, o que afetaria, diretamente, a operacionalidade da tropa e a

segurança dos quartéis, independentemente da quantidade da droga encontrada, e agrediria, dessa forma, os valores básicos das instituições militares...” (HC 94.685/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, 11.11.2010, *Inf. 608/STF*).

CUIDADO: o tema discutido envolvia **militar**. Contudo, imaginando a eventual possibilidade de crime praticado por *civil* (art. 9.º, III, do *Código Penal Militar*), sustentamos que o entendimento seria outro, até porque a ideia de **hierarquia** e **disciplina** deve ser analisada em relação aos **militares**. *O tema não foi discutido pelo STF (matéria pendente)*. Também estamos pensando como a *posse de maconha por civil em ambiente militar* (caso concreto dos referidos autos) poderia caracterizar eventual crime militar, por isso a imaginação em tese da discussão.²⁰ Finalmente, lembramos que, se caracterizado, o julgamento seria apenas pela **Justiça Militar da União**, já que a Justiça Militar Estadual não julga civis (art. 125, § 5.º, da CF/88).

■ 13.6.9. Criação do Ministério da Defesa pela EC n. 23/99

Como já referimos em notas anteriores, a EC n. 23, de 02.09.1999, criou o **Ministério da Defesa**.

Com a sua previsão, os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram transformados em **Comandos** (art. 20 da LC n. 97, de 09.06.1999,²¹ que, expressamente, revoga a LC n. 69, de 23.07.1991), passando os ex-Ministros a intitular-se **Comandantes** das respectivas Forças Armadas, sendo que os cargos de Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativos de oficiais-generais do último posto da respectiva Força.

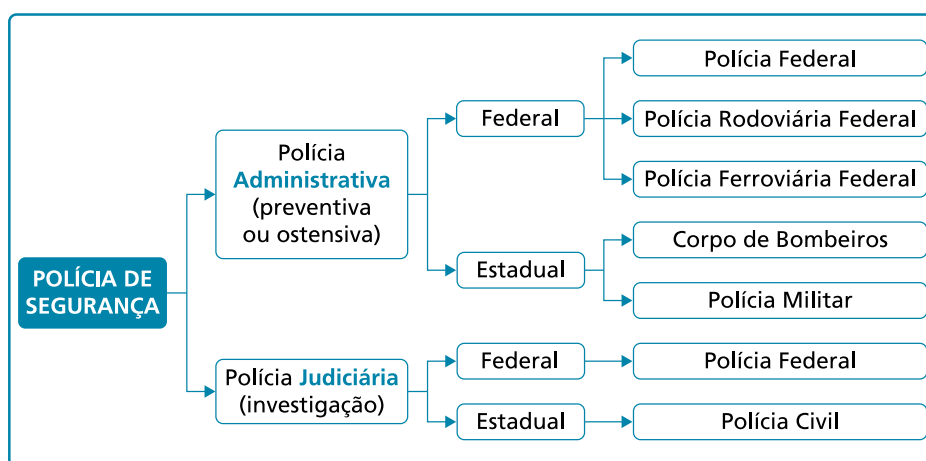
O Presidente da República, na condição de Comandante Supremo das Forças Armadas, será assessorado, no que concerne ao *emprego de meios militares*, pelo **Conselho Militar de Defesa**²² e, no que concerne aos *demaís assuntos pertinentes à área militar*, pelo **Ministro de Estado da Defesa**²³ (art. 2.º da LC n. 97/99).

As Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa (que exerce a **direção superior** das Forças

Armadas), dispondo de estruturas próprias. Cada qual, conforme visto, terá, singularmente, um **Comandante**, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (arts. 3.º e 4.º da LC n. 97/99).

Por fim, lembramos que, nos termos do art. 12, § 3.º, VII, o Ministro de Estado da Defesa deverá, dentre os requisitos previstos no art. 87, ser **brasileiro nato**, não estando este pressuposto estabelecido para os demais Ministros de Estado.

■ 13.7. SEGURANÇA PÚBLICA



■ 13.7.1. Aspectos gerais

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, adotando um conceito moderno, “o poder de polícia é a **atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público**”.²⁴

Assim, podemos distinguir **a)** polícia administrativa *lato sensu*; **b)** polícia de segurança, dividida esta em polícia administrativa (preventiva, que não deve confundir-se com a ideia de poder de polícia *lato sensu* do Estado) e polícia judiciária. Concentraremos a análise na **polícia de segurança**.

O objetivo fundamental da **segurança pública**, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é a **preservação da ordem pública** e da

O objetivo fundamental da **segurança pública**, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é a **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas** e do **patrimônio** e se implementa por meio dos seguintes **órgãos** (art. 144, I a V, CF/88):

- **polícia federal;**
- **polícia rodoviária federal;**
- **polícia ferroviária federal;**
- **polícias civis;**
- **polícias militares e corpos de bombeiros militares.**

Trata-se de **rol taxativo** e deverá ser observado no âmbito dos demais entes federativos, que não poderão criar novos órgãos distintos daqueles designados pela Constituição Federal. [25](#)

A atividade policial divide-se, então, em duas grandes áreas: administrativa (no sentido estrito indicado) e judiciária. A **polícia administrativa** (polícia preventiva, ou ostensiva) atua preventivamente, evitando que o crime aconteça. Já a **polícia judiciária** (polícia de investigação) atua repressivamente, depois de ocorrido o ilícito penal, exercendo atividades de apuração das infrações penais cometidas, bem como a indicação da autoria. Não lhe cabe a promoção da ação penal, atribuição essa privativa do Ministério Público nas ações penais públicas, na forma da lei (art. 129, I, CF/88).

De acordo com o art. 2.º, da Lei n. 12.830/2013, as funções de **polícia judiciária** e a apuração de **infrações penais exercidas pelo delegado de polícia** são de **natureza jurídica**, essenciais e exclusivas de Estado.

O cargo de **delegado de polícia** é **privativo de bacharel em Direito**, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados (art. 3.º da Lei n. 12.830/2013).

A citada **Lei n. 12.830/2013** trouxe diversas **garantias** ao dispor sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, destacando-se (art.

condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais;

durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos;

o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante **despacho fundamentado**, por **motivo de interesse público** ou nas **hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação**; a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por **ato fundamentado**. Sem dúvida, importante previsão da lei;

o indiciamento, **privativo do delegado de polícia**, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Todas essas regras estão sendo discutidas no STF no julgamento conjunto das ADIs 5.043, 5.059 e 5.073 (*pendentes*):

■ **ADI 5.043** — ajuizada pela *PGR*, objetiva seja declarado que o poder de investigação não é exclusivo da autoridade policial (sobre o tema, cf. *item 12.2.9* e julgamento plenário do **RE 593.727** em 14.05.2015);

■ **ADI 5.059** — ajuizada pela *Associação Nacional das Operadoras Celulares (ACEL)*, questiona o § 2.º, do art. 2.º, da citada lei, sustentando que, ao possibilitar ao delegado requisitar, durante a investigação criminal, perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos, haveria afronta aos incisos X e XII do art. 5.º da CF;

ADI 5.073 — ajuizada pela *Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL)*, requer seja declarada a inconstitucionalidade de toda lei por haver alteração da natureza das funções exercidas pelo delegado de polícia.

Tem razão José Afonso da Silva ao afirmar que “**segurança pública** não é só repressão e não é problema apenas de polícia, pois a Constituição, ao estabelecer

que a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144), acolheu a concepção do *I Ciclo de Estudos sobre Segurança* (realizado em out./1985, acrescente-se), segundo o qual é preciso que a questão da segurança seja discutida e assumida como **tarefa** e **responsabilidade permanente** de **todos, Estado** e **população**. Daí decorre também a aceitação de outras teses daquele certame, tal como a de que ‘se faz necessária uma nova concepção de ordem pública, em que a colaboração e a integração comunitária sejam os novos e importantes referenciais’; e a de que ‘(...) a amplitude da missão de manutenção da ordem pública, o combate à criminalidade deve ser inserido no contexto mais abrangente e importante da proteção da população’, o que requer a adoção de outro princípio ali firmado, de acordo com o qual é preciso ‘adequar a Polícia às condições e exigências de uma sociedade democrática, aperfeiçoando a formação profissional e orientando-a para a obediência aos preceitos legais de respeito aos direitos do cidadão, independentemente de sua condição social’”.[26](#)

Finalmente, a Constituição fez a previsão de verdadeira **lei orgânica** dos órgãos de segurança pública ao estabelecer que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a **eficiência de suas atividades** (art. 144, § 7.º). Até o fechamento desta edição, referida lei ainda não havia sido aprovada.

■ 13.7.2. Cooperação entre a União e os Estados-Membros e o DF e a Força Nacional de Segurança Pública

Com o objetivo de minimizar os efeitos danosos à população causados, por exemplo, pelas “greves” (visto que inadmitidas) em setores essenciais, como o da polícia militar, o Presidente da República adotou a MP n. 2.205, de 10.08.2001, convertida na Lei n. 10.277, de 10.09.2001, e que, posteriormente, foi revogada, passando a matéria a ser disciplinada pela **Lei n. 11.473, de 10.05.2007**.

De acordo com o novo dispositivo legal, a União poderá firmar **convênio**

com os Estados-Membros e o Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis à **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas e do patrimônio**.²⁷

Referida **cooperação federativa** compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da **Força Nacional de Segurança Pública**, sendo que as atividades terão caráter consensual e serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do ente federativo que firmar o convênio.

Sublinhamos, nessa linha de medidas, o **Decreto n. 5.289, de 29.11.2004**, que, disciplinando a organização e o funcionamento da Administração Pública federal, desenvolveu um programa de cooperação federativa denominado **Força Nacional de Segurança Pública**, em atenção ao **princípio da solidariedade federativa** (arts. 144 e 241 da CF/88).

A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional, mediante **solicitação expressa** do respectivo Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Ministro de Estado (Decreto n. 7.957/2013) e atuará somente em atividades de **policciamento ostensivo** (preventivo) destinadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido do Ministério da Justiça treinamento especial para atuação conjunta, integrantes das polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que tenham aderido ao programa de cooperação federativa.

“Inspirada nas forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), a Força Nacional de Segurança Pública foi criada pelo governo federal para apoiar os estados em momentos de crise”²⁸ (cf. diversas missões já realizadas no *Portal do Ministério da Justiça* — www.mj.gov.br).

■ 13.7.3. BEPE — Batalhão Especial de Pronto Emprego

Com o objetivo de destacar o assunto para os *ilustres candidatos aos concursos ligados à área de segurança pública*, lembramos que em setembro de 2008 iniciaram-se as atividades do **BEPE — Batalhão Especial de Pronto Emprego**, localizado em Luziânia (GO), região do entorno do DF.

“O Batalhão Especial de Pronto Emprego (BEPE) é um novo setor especializado da *Força Nacional de Segurança Pública* para o treinamento de policiais, que poderão atuar de forma imediata em situações de grave crise. Pela proposta, cada estado deve ceder os policiais por um ano, que retornarão aos locais de origem com todo o equipamento utilizado durante a capacitação, inclusive viaturas, armas letais e não letais, coletes e capacetes balísticos de última geração. A iniciativa visa disseminar tecnologia de ponta e conhecimento com foco principal na preservação da vida e no respeito aos Direitos Humanos”.

“A diferença entre o BEPE e as ações regulares da Força Nacional é, principalmente, o tempo de resposta às demandas dos estados e a permanência. Quando há o pedido de auxílio à Força Nacional, o Ministério da Justiça tem que convocar homens já treinados que retornaram aos estados de origem. Da requisição dos policiais até a chegada no local da crise, são necessários alguns dias. Com o BEPE, os homens já estarão aquartelados e poderão se deslocar rapidamente” (cf. *Notícias MJ*, 24.11.2008, 18h30).

■ 13.7.4. UPPs — Unidades de Polícia Pacificadora (RJ)

Vários modelos de políticas buscam a redução da violência, seja no Brasil, seja no mundo, associados ou não a intervenções sociais.

As UPPs, implantadas no final de 2008, não são um novo órgão, mas, basicamente, uma política de segurança estabelecida pelo Estado do Rio de Janeiro, buscando a **retomada de territórios antes controlados por criminosos** e, assim, sob o controle estatal, o restabelecimento da paz e da tranquilidade públicas ameaçadas. [29](#)

■ 13.7.5. Polícias da União

Os órgãos que compõem a polícia no âmbito federal são: **polícia federal**, **polícia rodoviária federal** e **polícia ferroviária federal**.

■ 13.7.5.1 Polícia Federal (PF)

A **polícia federal**, fundada na hierarquia e na disciplina, é integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça e será instituída por lei como órgão **permanente**, **organizado** e **mantido pela União**. Estruturada em **carreira**, destina-se a:

- apurar **infrações penais** contra a **ordem política**³⁰ e **social** ou em detrimento de **bens, serviços e interesses** da **União** ou de suas **entidades autárquicas** e **empresas públicas**, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão **interestadual** ou **internacional** e exija **repressão uniforme**, segundo se dispuser em lei;³¹
- prevenir e reprimir o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **contrabando** e o **descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
- exercer as funções de **polícia marítima**, **aeroportuária** e de **fronteiras**;
- exercer, com exclusividade, as funções de **polícia judiciária da União**.

A **Carreira Policial Federal** é composta pelos seguintes **cargos**:

- Delegado de Polícia Federal;
- Perito Criminal Federal (áreas 1 a 18);
- Escrivão de Polícia Federal;
- Papiloscopista Policial Federal;
- Agente de Polícia Federal.

Todos esses **cargos** são de **nível superior** e o ingresso ocorrerá sempre na terceira classe, mediante **concurso público**, de **provas** ou de **provas e títulos**, exigido o **curso superior completo**, em nível de graduação, observados os

terceira classe, mediante **concurso público**, de **provas** ou de **provas e títulos**, exigido o **curso superior completo**, em nível de graduação, observados os requisitos fixados na legislação pertinente (art. 2.º da Lei n. 9.266/96). [32](#)

Apesar de todos os cargos integrarem a mesma carreira e serem de nível superior, há diferença remuneratória em relação aos chamados **EPAs** (escrivães, papiloscopistas e agentes) e que tem gerado eterna tensão política entre os seus integrantes. Vejamos (Leis ns. 12.775/2012 e 13.034/2014):

CARGO	CLASSE	VALOR DO SUBSÍDIO APARTIR DE 1.º.01.2015
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL PERITO CRIMINAL FEDERAL	■ especial	■ R\$ 22.805,00
	■ primeira	■ R\$ 20.256,59
	■ segunda	■ R\$ 17.330,34
	■ terceira	■ R\$ 16.830,85
ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL	■ especial	■ R\$ 13.756,93
	■ primeira	■ R\$ 10.965,77
	■ segunda	■ R\$ 9.132,61
	■ terceira	■ R\$ 8.702,20

No final de 2014, tivemos a introdução de novas regras em relação ao cargo de **delegado de polícia federal**, destacando-se a previsão explícita de que os

autorizados a exercer funções dessa natureza (sem dúvida, trata-se de inegável conquista dos delegados de polícia, frustrando expectativas dos integrantes dos demais cargos da carreira policial). [34](#)

Em razão dessa previsão (exercício de função de natureza jurídica), houve a **ampliação de requisitos mínimos** para o ingresso no cargo de **delegado de polícia federal**: o concurso público, que é privativo de bacharel em direito, será de provas e títulos, com a participação da **OAB** e passou a exigir **3 anos** de **atividade jurídica** ou **policial**, comprovados no ato de **posse** (esse modelo de *quarentena de entrada* já havia sido introduzido para os cargos de juiz de direito e membro do Ministério Público pela EC n. 45/2004 — *Reforma do Poder Judiciário*).

Outro ponto de definição foi em relação ao **cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal**. Até o advento da MP n. 657/2014, convertida na Lei n. 13.047/2014, referido cargo era de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República. Assim, diante da inexistência de explicitação dos requisitos, a Polícia Federal já teve como Diretor-Geral **militares**. Após o regime ditatorial, somente em 1986 a Polícia Federal teve um diretor civil que, no caso, era da Polícia Civil de São Paulo (Romeu Tuma). O primeiro integrante da própria carreira e, no caso, delegado de polícia federal, foi Amaury Aparecido Galdino, em 1992. Entre 1993 e 1995, tivemos, novamente, um militar (o Coronel Wilson Brandi Romão). A partir de 1995, até o advento da referida lei no final de 2014, mesmo sem a previsão normativa, na prática, todos os diretores-gerais foram escolhidos dentre delegados de polícia federal. [35](#)

Depois de quase 20 anos, essa praxe de escolha virou **regra normativa**. De acordo com o art. 2.º-C, da Lei n. 9.266/96 (introduzido pela Lei n. 13.047, de 02.12.2014), o cargo de **Diretor-Geral**, nomeado pelo Presidente da República, é **privativo** de **delegado de Polícia Federal** integrante da **classe especial**. [36](#)

■ 13.7.5.2. **Polícia Rodoviária Federal (PRF)**

A **polícia rodoviária federal**, órgão **permanente**, organizado e mantido pela

União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo** das **rodovias federais**. Não exerce, portanto, funções de polícia judiciária, visto que exclusividade da **polícia federal** (art. 144, § 1.º, IV).

O cargo de Policial Rodoviário Federal é regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União (Lei n. 8.112/90) e pela Lei n. 9.654/98, com as suas alterações. A Lei n. 12.775/2012, dando nova redação à Lei n. 9.654/98 (que cria a carreira), estabeleceu que, a partir de 1.º.01.2013, o cargo de Policial Rodoviário Federal passa a ser de **nível superior**, estando a carreira estruturada nas seguintes classes: terceira, segunda, primeira e especial, na forma do Anexo I-A, observada a correlação disposta no Anexo II-A.

Compete à **Polícia Rodoviária Federal** realizar atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*, estando as competências descritas nos seguintes dispositivos (e que remetemos os nossos ilustres leitores, especialmente aqueles que prestam esse concurso público específico):

Art. 20 do **Código de Trânsito Brasileiro** — Lei n. 9.503/97;

■ **Decreto n. 1.655/95**;

■ **Regimento Interno**, aprovado pela Portaria Ministerial n. 3.741/2004.

■ **13.7.5.3. Polícia Ferroviária Federal (PFF)**

A **polícia ferroviária federal**, por seu turno, também órgão **permanente**, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo** das **ferrovias federais**.

Historicamente, podemos lembrar, durante o Império, a edição do Decreto n. 641/1852 que instituiu a então denominada “**Polícia dos Caminhos de Ferro**”.

Observamos, contudo, mesmo diante do explícito comando constitucional (art. 144, § 3.º), a **inexistência de plano de carreira**.

De acordo com o art. 29, § 8.º, da Lei n. 10.683/2003, introduzido pela Lei n. 12.462/2011, os profissionais da Segurança Pública Ferroviária oriundos do grupo Rede, Rede Ferroviária Federal (RFFSA), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (TRENSURB) que estavam em exercício em 11.12.1990, passam a integrar o **Departamento de Polícia Ferroviária Federal do Ministério da Justiça**.

Em 2011, foi editada a Portaria do Ministro da Justiça n. 2.158, com o objetivo de analisar alternativas para implementação do disposto no citado § 8.º do art. 29 da Lei n. 10.683/2003, elaborar plano de trabalho e efetuar as recomendações aos órgãos competentes.

Até o fechamento desta edição, contudo, a perspectiva lançada pela Lei n. 12.462/2011 (de se implementar e resgatar a *polícia dos trilhos*) ainda não era realidade. Como bem observou Cláudio Pereiro de Souza Neto, “o que há, na prática, é apenas a segurança patrimonial exercida pelas próprias empresas concessionárias de serviço ferroviário”. [37](#)

■ 13.7.6. Polícias dos Estados

A **segurança pública** em nível estadual foi atribuída às **polícias civis**, às **polícias militares** e ao **corpo de bombeiros**, organizados e mantidos pelos Estados (ao contrário da regra fixada para o Distrito Federal, que são organizados e mantidos pela União — art. 21, XIV).

Apesar dessa regra de organização e manutenção estadual, deverão ser observadas as **normas gerais federais** (da União) sobre organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, além daquelas sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (arts. 22, XXI, e 24, XVI).

Os integrantes das **polícias civis** devem ser reconhecidos como servidores estaduais civis (arts. 39 a 41) enquanto, por outro lado, os das **polícias militares** e os dos **corpos de bombeiros militares**, como servidores militares dos Estados (art. 42).

■ 13.7.6.1. *Polícia civil estadual*

As **polícias civis** são dirigidas por **delegados de polícia de carreira**, incumbindo-lhes, ressalvada a competência da União (polícia federal), as funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais**, exceto as militares.

De acordo com a Constituição, as polícias civis estaduais subordinam-se aos Governadores dos Estados (art. 144, § 6.º).

■ 13.7.6.2. *Nos Municípios em que o Departamento de Polícia Civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia de carreira, o atendimento nas delegacias de polícia poderá ser realizado por subtenente ou sargento da polícia militar?*

O STF entendeu que a polícia de investigação só pode ser exercida pela **polícia civil**, e não pela PM, sob pena de se caracterizar desvio de função: “Constitucional. Administrativo. Decreto n. 1.557/2003 do Estado do Paraná, que atribui a subtenentes ou sargentos combatentes o atendimento nas delegacias de polícia, nos municípios que não dispõem de servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia. Desvio de função. Ofensa ao art. 144, *caput*, inc. IV e V e §§ 4.º e 5.º, da Constituição da República. Ação direta julgada procedente” (ADI 3.614, Rel. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 20.09.2007, *DJ* de 23.11.2007).

■ 13.7.6.3. *Polícia judiciária dos Estados — discussão sobre a escolha do diretor-geral da Polícia Civil. Superação do entendimento firmado na ADI 132. Reconstrução jurisdicional da própria teoria do federalismo (ADI 3.062). Análise da ADI 3.038*

A investigação e a apuração de infrações penais (exceto militares e aquelas de competência da polícia federal), ou seja, o exercício da **polícia judiciária**, em âmbito estadual, couberam às **polícias civis**, dirigidas por **delegados de polícia**

de carreira (art. 144, § 4.º).

Nesse ponto específico, o STF discutiu a regra contida no art. 6.º, parágrafo único, “a”, da *Lei estadual de Goiás n. 11.438/91*, que restringiu a escolha, pelo Governador, do diretor-geral da Polícia Civil aos *delegados de carreira da classe mais elevada*.³⁸

A ação foi proposta pela PGR, que “sustentava que a inclusão da expressão ‘**da classe mais elevada**’ (...) contrariaria o artigo 144, § 4.º, da Constituição Federal, segundo o qual as polícias civis devem ser dirigidas por ‘**delegados de polícia de carreira**’. De acordo com a inicial, ‘a Constituição Federal não traz esta limitação, prevendo, apenas, que as polícias civis serão dirigidas por delegados de carreira’” (*Notícias STF*, 09.09.2010).

O STF, por maioria, vencido o Min. Dias Toffoli, que seguia entendimento então prevalente, firmado na *ADI 132* (j. 30.04.2003), que declarava inconstitucional dispositivo semelhante constante da Constituição do Estado de Rondônia, **evoluiu a jurisprudência e modificou o seu posicionamento**, passando a entender que o Estado, ao disciplinar o assunto, tem competência legislativa para **estabelecer um requisito a mais**, ou seja, além da regra mínima prevista no art. 144, § 4.º, que exige ser o diretor integrante da respectiva **carreira**, que tenha **experiência** e, portanto, o cargo em comissão, de acordo com a referida regra estadual, deva ser preenchido por delegado da carreira **da classe mais elevada**, escolhido pelo Governador do Estado, prestigiando, dessa forma, a **autonomia político-institucional da Federação**.

Assim, “mencionou-se que a Constituição não poderia deixar de pressupor que a **carreira** significaria **experiência e profissionalização do serviço público**. Aduziu-se que o STF vem possibilitando uma verdadeira *reconstrução jurisdicional da própria teoria do federalismo*, **afastando** aquela anterior subordinação dos Estados-membros e dos Municípios ao denominado ‘*standard federal*’ tão excessivamente centralizador da CF/69, na qual estabelecida uma concentração espacial do poder político na esfera da União. Tendo isso em conta, ressaltou-se que a **federação brasileira fora uma construção artificial e que caberia a esta Corte auxiliar na arquitetura dessa autonomia**

conta, ressaltou-se que a **federação brasileira fora uma construção artificial e que caberia a esta Corte auxiliar na arquitetura dessa autonomia estadual**” (ADI 3.062, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.09.2010, Plenário, DJE de 12.04.2011, Inf. 599/STF).

Dessa forma, conforme fixado no *item 6* da ementa do referido acórdão, o critério estabelecido de se exigir, também, que o delegado geral seja da classe mais elevada da carreira de delegado de polícia “não só se coaduna com a exigência constitucional como também a reforça, por subsidiar o adequado exercício da função e valorizar os quadros da carreira”.

Apesar de estar claro esse **novo e melhor** entendimento firmado pelo STF na referida ADI 3.062, inclusive com o voto do Min. Marco Aurélio, tendo a Corte superado a posição estabelecida na ADI 132, deixamos a **informação** de julgamento posterior sobre o mesmo tema (ADI 3.038, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2014, Plenário, DJE de 12.02.2015), envolvendo o art. 106, § 1.º, da Constituição do Estado de Santa Catarina que, em sua redação original, exigia que o delegado de polícia, para ser indicado como Diretor-Geral, estivesse no final da carreira. Na redação posterior, também analisada pelo STF, dada pela EC n. 18/99, a Constituição do referido Estado passou a estabelecer que a escolha se daria entre os delegados de polícia, sem usar o qualificativo “de carreira” e o requisito a mais de estar no “final da carreira”.

A **ementa** de referido julgado afirma ser inconstitucional a exigência de estar o delegado no último nível da organização policial.

Contudo, lendo o acórdão, **essa questão não foi analisada pelo STF**, pois, o que se verificou foi apenas a indicação da interpretação conforme a Constituição (ser delegado de carreira).

Esse novo julgamento, depois de mais de 11 anos de tramitação da ação, durou menos de **2 minutos**! Isso mesmo, 2 minutos e sem a manifestação de qualquer outro Ministro. Portanto, não houve debate. Entendemos, então, que a ementa do acórdão não reflete o posicionamento da Corte firmado na ADI 3.062.

Pensamos que a melhor interpretação é no sentido de que os entes federativos

que ingressaram por **concurso público** — art. 144, § 4.º), criar **mais um requisito** tido como razoável (**ADI 3.062**), qual seja, que a escolha tenha que se dar em relação aos delegados integrantes do mais alto nível da carreira.

Nesse sentido de ampliação de requisitos, destacamos a **Lei Federal n. 13.047, de 02.12.2014**, que estabeleceu que o cargo de Diretor-Geral a ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo deve ser privativo de delegado de polícia integrante da **classe especial** (a lei trata tanto da polícia federal — e, no caso, a nomeação dar-se-á pelo Presidente da República, como da polícia do DF, hipótese em que a nomeação será feita pelo Governador do Distrito Federal).

■ 13.7.6.4. *Polícia ostensiva ou preventiva dos Estados — PM e Corpo de Bombeiros Militares*

Já a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (**polícia administrativa**) ficaram a cargo das **polícias militares**, forças auxiliares e reserva do Exército. [39](#)

Aos **corpos de bombeiros militares**, também considerados forças auxiliares e reserva do Exército, além das atribuições definidas em lei (por exemplo, prevenção e extinção de incêndios, proteção, busca e salvamento de vidas humanas, prestação de socorro em casos de afogamento, inundações, desabamentos, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas etc.), incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Tanto as polícias civis como as militares e o corpo de bombeiros **subordinam-se** aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 144, § 6.º).

Apenas para explicitar, devemos destacar que os **militares** são não só os integrantes das **Forças Armadas** (*Marinha, Exército e Aeronáutica* — art. 142), mas também os integrantes das **Forças Auxiliares e reserva do Exército** (*polícias militares e corpos de bombeiros militares* — art. 42, *caput*, c/c o art. 144, § 6.º). Os primeiros estão organizados em **nível federal** (como vimos, as **Forças Armadas** são instituições **nacionais**), enquanto os membros das polícias

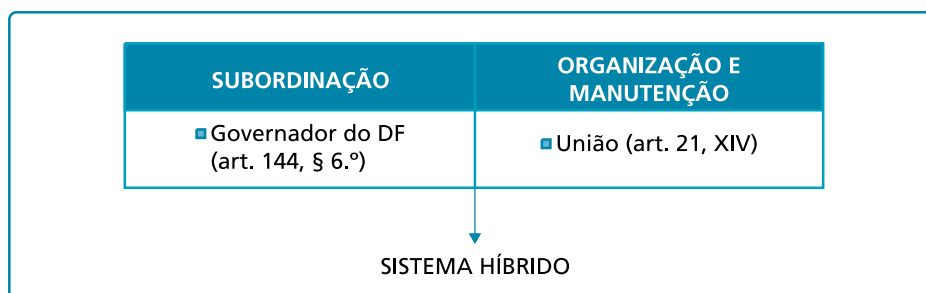
militares e dos corpos de bombeiros militares, instituições organizadas, também, com base na hierarquia e disciplina, em **nível estadual, distrital** ou dos **Territórios**.

Não obstante a **EC n. 18/98** tenha procurado tratar separadamente os **militares das Forças Armadas** e os **militares dos Estados, do DF e dos Territórios**, o art. 42, § 1.º, estabelece que se aplicam a estes últimos, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8.º; do art. 40, § 9.º; e do art. 142, §§ 2.º e 3.º, **40** cabendo à **lei estadual específica** dispor sobre as matérias do art. 142, § 3.º, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Em relação à definição específica da **remuneração** (art. 142, § 3.º, X), entendeu o STF que o **impedimento** constante no art. 13, § 4.º, da Constituição de 1967, na redação dada pela EC n. 1/69, que proibia o pagamento de remuneração aos militares estaduais (e do DF) superior à fixada para os postos e graduações correspondentes no Exército, **não foi mantido na Constituição de 1988**. Assim, a remuneração poderá ser superior e, ainda, no caso, se superior, esse parâmetro remuneratório não poderá servir de fundamento para a equiparação remuneratória.

Como bem definiu o STF, “o **art. 37, XIII**, da CF/88 **coíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no âmbito do serviço público**. Destarte, a pretensão dos recorrentes se afigura evidentemente incompatível com a Constituição Federal de 1988, uma vez que importa a equiparação de vencimentos entre os integrantes das Forças Armadas e os militares do Distrito Federal. Precedentes de ambas as Turmas em casos idênticos: ARE 652.202-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, 1. T., *DJE* de 17.09.2014; ARE 651.415-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2. T., *DJE* de 25/4/2012” (**ARE 665.632**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015, Plenário, *DJE* de 28.04.2015).

■ 13.7.7. Polícias do Distrito Federal



Conforme já explicitamos, o **art. 32, § 4.º**, declara inexistirem polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar pertencentes ao Distrito Federal, devendo lei federal dispor sobre a sua **utilização** pelo Governo do Distrito Federal.

Tais instituições, embora **subordinadas** ao **Governador do Distrito Federal** (art. 144, § 6.º), são **organizadas** e **mantidas** diretamente pela **União** (regra essa reforçada pela redação conferida ao **art. 21, XIV**, pela EC n. 19/98).

Consagra-se, dessa forma, um **regime jurídico híbrido**, particular aos integrantes da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do DF. Referidos organismos estão sujeitos à disciplina fixada em **lei federal**, editada pelo Congresso Nacional, e não pela Câmara Legislativa do DF, concernente aos vencimentos de seus membros.^{[41](#)}

Esse entendimento está consagrado na **Súmula Vinculante n. 39/STF**, que tem a seguinte redação: “compete privativamente à **União** legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal” (aprovada em **11.03.2015**, fruto de conversão da S. 647/STF, com a inclusão da expressão “e do corpo de bombeiros militar”, *DJE* de 20.03.2015).

Conforme visto no item anterior, a lei (no caso, **federal**) poderá estabelecer remuneração superior para os militares do DF em relação aos militares das Forças Armadas e, no caso, em razão da proibição de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias pela CF/88 (art. 37, XIII), os integrantes dessas últimas não poderão pleitear judicialmente a equiparação remuneratória (**ARE 665.632**, j. 16.04.2015).

Por serem organizados e **mantidos** pela União, a nosso ver o controle das contas deve ser feito pelo TCU, e não pelo TCDF (**matéria pendente de**

apreciação pelo STF).

Finalmente, questão interessante foi resolvida pelo STF envolvendo o art. 7.º, I e III, da **Lei Distrital n. 3.669/2005**,⁴² que, ao criar a *Carreira de Atividades Penitenciárias*, estabeleceu atribuições de **administração penitenciária**, como a de *guarda dos estabelecimentos prisionais*, para o cargo criado de **técnico penitenciário**.

Diante da regra contida no art. 21, XIV, discutiu-se se a atividade de *carceragem de presídios* seria ou não atividade ligada à *segurança pública* e, nesse caso, de iniciativa reservada ao *Congresso Nacional*.

O art. 144, § 4.º, da CF/88, estabelece incumbirem às polícias civis, ressalvada a competência da União, “as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”, não se referindo a **atividades penitenciárias**, como, para se ter um exemplo, a guarda dos estabelecimentos prisionais, indicado acima.

Assim, decidiu o STF, no julgamento da **ADI 3.916** (Rel. Min. Eros Grau, j. 03.02.2010), que as atividades criadas pela lei distrital para os Técnicos Penitenciários poderiam ser disciplinadas no âmbito do DF, por se tratar **não** de atividades específicas ligadas à polícia civil (*segurança pública*), mas de **direito penitenciário**, cuja competência é **concorrente** entre o DF, no caso, e a União, nos termos do art. 24, I.

■ 13.7.8. Polícias dos Territórios

Embora os Territórios sejam uma descentralização administrativa da União, integrando-a, a EC n. 19/98, alterando a redação do art. 21, XIV, da CF/88, não mais previu para a União (pelo menos expressamente) a atribuição de organização e manutenção das **polícias civil e militar**, e **do corpo de bombeiros dos Territórios**, endereçando referida regra apenas e **exclusivamente** ao Distrito Federal. Resta aguardar como os tribunais interpretarão a proposital exclusão dos Territórios da redação dada ao inciso XIV do art. 21, que conferia à União o dever de organizar e manter as referidas

polícias dos Territórios, o que, dada a natureza destes, de autarquias federais — uma *longa manus* da União —, continuarão, em nossa análise, sendo organizados e mantidos pela União.

Por fim, entendendo tratar-se de tema muito específico, e procurando cumprir os objetivos deste trabalho, destacamos o **art. 31 da EC n. 19/98**, aperfeiçoado pela **EC n. 79/2014⁴³** que estabeleceu: “os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do **Amapá** e de **Roraima** que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados, os servidores e os policiais militares admitidos regularmente pelos governos dos Estados do Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação desses Estados em outubro de 1993 e, ainda, os servidores nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União integrarão, mediante opção, **quadro em extinção da administração federal**”.

O enquadramento referido para os servidores ou para os policiais militares admitidos regularmente entre a transformação e a instalação dos Estados em outubro de 1993 deverá dar-se no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.

Os integrantes da carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de **cedidos**, submetidos às disposições estatutárias a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observados as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico e o direito às devidas promoções.

Os servidores a que se refere continuarão prestando serviços aos respectivos Estados e a seus Municípios, **na condição de cedidos**, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional.

Como se percebe, a **Reforma Administrativa** (1998) não beneficiou os integrantes da **polícia militar** do **ex-Território de Rondônia**, transformado em Estado pela **LC n. 41, de 22.12.1981**, assim como os **policiais militares**

Estado pela **LC n. 41, de 22.12.1981**, assim como os **policiais militares** admitidos por força de lei federal, custeados pela União. Em razão dessa flagrante discriminação, procurando determinar as mesmas regras já trazidas pela **EC n. 19/98**, vedando, ainda, ressarcimentos ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à sua promulgação, e prestigiando o **princípio da isonomia**, a **EC n. 38, de 12.06.2002**, também estabeleceu que os integrantes da **polícia militar** do **ex-Território de Rondônia** (apenas **553 pessoas!**) constituirão **quadro em extinção da União**, continuando a prestar os serviços na condição de **cedidos**.

Nessa evolução, houve outra modificação, agora trazida pela **EC n. 60, de 11.11.2009**.

Referida emenda eliminou qualquer dúvida, porventura ainda existente, sobre quem estaria abarcado pela nova sistemática. Assim, além dos integrantes da carreira policial militar, deixou claro que constituirão quadro em extinção os policiais militares alcançados pelo disposto no **art. 36 da LC n. 41/81** (quais sejam, aqueles que foram custeados pela União por 10 anos, isto é, até 1991), bem como os admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15.03.1987 (segundo a justificativa, pois, até referida data, o Governador era nomeado pelo Presidente da República e, assim, o Estado não tinha uma total e ampla autonomia federativa, estando, de certa forma, ainda atrelado à União).

Cabe observar que a EC n. 60/2009 deixou claro que a caracterização do *quadro em extinção da administração federal* dependerá de **opção** do servidor ou integrante da carreira policial militar, o que não havia estabelecido o art. 31 da EC n. 19/98 em sua redação original.

É de ressaltar, ainda, que a EC n. 60/2009 corrigiu outra distorção, também não contemplada pela EC n. 38/2002.

Isso porque a reforma em 2002 abarcou **apenas** os integrantes da **carreira policial militar** do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviços àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os **policiais**

Já a EC n. 60/2009, além de definir claramente quais integrantes da carreira policial militar estariam abarcados — como já havia estabelecido o art. 31 da EC n. 19/98 em relação aos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima —, acrescentou que poderão também optar por constituir cargo em extinção da administração federal os **servidores municipais** os quais, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores alcançados pelo disposto no art. 36 da LC n. 41/81 (ingressantes até o ano de 1991), e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987.

Em virtude dessa ampliação, o § 2.º do art. 89 do ADCT estabeleceu que os servidores a que se refere o *caput* continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de **cedidos**, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional.

Para fins do enquadramento disposto no *caput* do art. 31 da EC n. 19/98, e no *caput* do art. 89 do ADCT, foi reconhecido expressamente pela **EC n. 79/2014** o vínculo funcional, com a União, dos servidores regularmente admitidos nos quadros dos Municípios integrantes dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia em efetivo exercício na data de transformação desses ex-Territórios em Estados.

Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da União foram enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.

Ainda, os proventos das aposentadorias, pensões, reformas e reservas remuneradas, originadas no período de outubro de 1988 a outubro de 1993 (5 anos, incorporado pela EC n. 79/2014 seguindo parâmetro fixado pelo STF no julgamento do RE 396.547), passam a ser mantidos pela União a partir da data de publicação da referida emenda constitucional, vedado o pagamento, a qualquer título, de valores referentes a períodos anteriores a sua publicação.

Finalmente, nesses casos específicos, de servidores da União e cedidos para os Estados, parece-nos que o controle de contas, já que estão vinculados à União, deva ser feito pelo TCU, e não pelo TCE (*matéria pendente de apreciação explícita pelo STF*).

■ 13.7.9. Policiais civis e militares: direito de greve (?) e anistia (?)

■ 13.7.9.1. Direito de greve?

Conforme vimos, nos termos do art. 142, § 3.º, IV, ao **militar** são proibidas a sindicalização e a greve.

Assim, os membros das **Forças Armadas** (Marinha, Exército e Aeronáutica), bem como os **militares dos Estados, do DF e dos Territórios** (membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares — art. 42, § 1.º, que determina a aplicação do art. 142, § 3.º) estão **proibidos** de exercer o direito de greve, confirmando, então, que referido direito fundamental não é absoluto.

E os integrantes da polícia civil, poderiam exercer o direito de greve?

Em tese, por serem servidores públicos (e não militares), poderiam, aplicando-se o art. 37, VII, especialmente diante das decisões proferidas pelo STF nos MIs 670, 708 e 712, o qual, adotando a posição **concretista geral**, assegurou o direito de greve a todos os servidores públicos, determinando a aplicação da lei do setor privado, qual seja, a Lei n. 7.783/89, até que a matéria seja regulamentada por lei.

Contudo, em momento seguinte, e restringindo a decisão tomada nos referidos mandados de injunção, o STF entendeu que alguns serviços públicos, em razão de sua **essencialidade** para a sociedade, deverão ser prestados em sua **totalidade**, como é o caso do **serviço de segurança pública**, determinando, por analogia, a aplicação da vedação para os militares e, assim, proibindo, o seu exercício pelas polícias civis. Pedimos vênias para transcrever o importante julgado:

“EMENTA: (...) 2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à **manutenção da ordem pública e à segurança pública**, à **administração da Justiça** — aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária — e à **saúde pública**. **A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve.** Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. (...) Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, **contudo**, que entre os serviços públicos há alguns que a **coesão social** impõe sejam prestados **plenamente**, em sua **totalidade**. Atividades das quais dependam a **manutenção da ordem pública** e a **segurança pública**, a **administração da Justiça** — onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária — e a **saúde pública** não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. **Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve** [art. 142, § 3.º, IV] (...)” (**Rcl 6.568**, Rel. Min. Eros Grau, j. 20.05.2009, Plenário, *DJE* de 25.09.2009).

Nessa mesma linha o Min. Peluso se pronunciou ao cassar, em sede da **AC 3.034**, decisão de Des. do TJDFt que permitiu o exercício de greve pelos policiais civis (**matéria pendente de apreciação** pelo Pleno do STF). Em suas palavras, “... a interpretação unitária da Constituição me leva, junto com o eminente Relator no seu belo voto (*refere-se à Rcl 6.568, acrescente-se*), a concluir que **os policiais não têm direito de greve**, assim como não o têm outras categorias, sobre as quais não quero manifestar-me na oportunidade, porque seria impertinente. E não o têm, porque lhes incumbem, nos termos do art. 144, *caput*, dois **valores incontornáveis da subsistência de um Estado: segurança pública** e a **incolumidade das pessoas e dos bens**. Ora, é inconcebível que a Constituição tutele estas condições essenciais de sobrevivência, de coexistência, de estabilidade de uma sociedade, de uma nação, permitindo que os responsáveis pelo resguardo desses valores possam, por

exemplo, entrar em greve, reduzindo seu efetivo a vinte por cento” (AC 3.034, Rel. Cezar Peluso, j. 16.11.2011, *decisão monocrática da Presidência*, DJE de 23.11.2011).

■ **13.7.9.2. Lei poderá conceder anistia a policiais civis ou militares (PM e Corpo de Bombeiros) em relação a eventuais crimes praticados e infrações disciplinares conexas decorrentes de participação em movimentos reivindicatórios?**

A **anistia** caracteriza-se como uma espécie de clemência, de indulgência, de perdão do Estado, que, motivado por razões políticas, renuncia ao seu direito de punir em relação a delito cometido no passado.

Deve-se deixar claro que a anistia não abole o crime (*abolitio criminis*), já que só será aplicada a **atos passados**, estando, pois, fixada como uma das **causas extintivas de punibilidade** (art. 107, II, do CP).

De acordo com o art. 5.º, XLIII, da CF/88, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou **anistia** a prática da **tortura**, o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **terrorismo** e os definidos como **crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

O art. 21, XVII, da CF/88, por sua vez, define que a competência para conceder **anistia** é da **União**, cabendo ao **Congresso Nacional**, por meio de **lei** e com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a matéria (art. 48, VIII), regra essa completada pelo art. 22, I, que estabelece ser competência da União legislar sobre **direito penal**.

Diante dessas premissas, lembramos duas **leis federais** que concederam **anistia** aos **policiais e bombeiros militares** de determinados Estados, por terem participado de **movimentos reivindicatórios**.

A **Lei federal n. 12.191/2010** (art. 2.º), e a **Lei federal n. 12.505/2011** (art. 2.º), ampliada pela **Lei Federal n. 12.848/2013**, estabeleceram que a anistia abrange não só os **crimes** definidos no **Código Penal Militar**, como também as **infrações disciplinares conexas**, *não incluindo os crimes definidos no Código*

Penal e nas leis penais especiais.

Fica claro, então, que a intenção do legislador, por meio de **ato normativo federal**, foi não só **perdoar** eventuais **crimes militares** praticados, como o *motim* (art. 149 do CPM⁴⁴), a *deserção* (art. 187 do CPM⁴⁵), a *desobediência* (art. 301 do CPM⁴⁶) etc., **como também** — e o texto é expresso — supostas **infrações administrativas**, decorrentes de **transgressões disciplinares**, **impossibilitando**, pois, a imposição e a aplicação de **punições disciplinares** previstas nos *Regulamentos* das Forças.

A primeira lei está sendo discutida no STF na **ADI 4.377** e a segunda na **ADI 4.869**, não havendo, ainda, decisão pela Corte (**matéria pendente**).

Não resta dúvida de que a **anistia** estabelecida pela lei federal pode alcançar a **infração penal militar**, não havendo, para a hipótese, a fixação de iniciativa reservada ao Presidente da República, já que não consta tal matéria no rol do art. 61, § 1.º, I e II, da CF/88.

A questão que precisa ser decidida é se a lei federal poderia tratar de anistia a **infrações disciplinares**, supostamente praticadas por **militares estaduais**.

De acordo com o **parecer da PGR** na ADI 4.377 (apresentado em 19.03.2010), no tocante a servidores estaduais, sugere-se a necessidade de se aplicar o art. 61, § 1.º, II, “c” e “f”, que, conforme vem entendendo o STF, determina a iniciativa exclusiva dos Governadores de Estado para disciplinar a matéria (imaginando que nas alíneas se enquadraria a *anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais*), sob pena de se ferir o **princípio federativo** e o **princípio da divisão funcional do poder**, bem como o dito “princípio da reserva de administração” (ADI 1.440).

Ainda, continua a PGR, se formos analisar a questão do ponto de vista das **infrações disciplinares** supostamente praticadas pelos **servidores estaduais militares**, outros argumentos poderiam ser lançados, **fortalecendo a ideia da necessidade de lei estadual e de iniciativa reservada ao Governador de cada Estado**, destacando-se:

art. 144, § 6.º: estabelece que polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, **subordinam-se**,

art. 144, § 6.º: estabelece que polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, **subordinam-se**, juntamente com polícias civis, aos **Governadores** dos **Estados**. Assim, a análise de conveniência da anistia em relação às supostas *infrações disciplinares* (e não se está falando dos crimes) deveria partir do Chefe do Executivo;

art. 22, XXI: a competência da **União** restringe-se às **normas gerais** de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

art. 42, § 1.º: aplicam-se aos militares dos Estados, além do que vier a ser fixado em lei, dentre outras, as disposições do art. 142, § 3.º, IV (**proibição da sindicalização e da greve**), cabendo à **lei estadual específica** dispor sobre as matérias do art. 142, § 3.º, X (**direitos e deveres** dos militares estaduais).

Um ponto não gera nenhuma dúvida, qual seja, a perfeita possibilidade de **lei federal** estabelecer a **anistia de crimes**, inclusive de supostos crimes militares previstos no *Código Penal Militar*.

No tocante às *supostas infrações disciplinares* praticadas por servidores estaduais (militares estaduais, ou até mesmo policiais civis estaduais), temos imaginado que, muito embora se reconheça a competência estadual para a matéria, **desde que por lei de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo**, parece razoável sustentar, em concorrência, a possibilidade de ser concedida anistia também por lei federal do Congresso Nacional.

Isso porque, como as infrações decorrentes dos movimentos reivindicatórios caracterizam-se, em tese, como crimes e, em sendo essas infrações disciplinares conexas com referidos ilícitos, parece lógico reconhecer não somente a competência estadual como **também** a da União, estabelecendo-se, então, um sentido mais **amplo** para o instituto da **anistia**. Nesse sentido:

“EMENTA: Anistia a funcionários civis e a elementos da força pública estadual. 1. **No direito brasileiro, a palavra ‘anistia’ foi ampliada de sua aceção clássica e etimológica, para abranger também o cancelamento de débitos fiscais e de faltas disciplinares.** Não há cláusula na constituição

executivo dentro da lei” (RP 696, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 06.10.1966, Plenário, DJ de 15.06.1967).

“EMENTA: (...) **Anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais**: competência do Estado-membro respectivo. Só quando se cuidar de anistia de crimes — que se caracteriza como *abolitio criminis* de efeito temporário e só retroativo — a competência exclusiva da União se harmoniza com a competência federal privativa para legislar sobre Direito Penal; ao contrário, conferir à União — **e somente a ela** — o poder de anistiar infrações administrativas de servidores locais constituiria exceção radical e inexplicável ao dogma fundamental do princípio federativo — qual seja, a autonomia administrativa de Estados e Municípios — que não é de presumir, mas, ao contrário, reclamaria norma inequívoca da Constituição da República (precedente: RP 696, 06.10.1966, Rel. Min. Aliomar Baleeiro). Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o **cancelamento**) **de infrações disciplinares de seus respectivos servidores**, podendo concedê-la a Assembleia Constituinte local, mormente quando circunscrita — a exemplo da concedida pela Constituição da República — às punições impostas no regime decaído por motivos políticos” (ADI 104, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04.06.2007, Plenário, DJ de 24.08.2007).

Não estamos defendendo que o ato normativo federal (ou mesmo estadual) possa assegurar ao militar a sindicalização e a “greve”, o que, inquestionavelmente, seria (flagrantemente) inconstitucional, por afronta ao art. 142, § 3.º, IV. Também não estamos propondo que os policiais civis tenham o direito de greve, até porque o STF, no julgamento da **Rcl 6.568**, entendeu tratar-se de atividades análogas às dos militares e, assim, não estendeu o direito de greve que havia sido fixado aos servidores públicos em geral no julgamento dos MIs 670, 708 e 712 (cf. *item 14.11.5.4*).

Contudo, diante de movimentos reivindicatórios, não podemos, especialmente dentro do Estado Democrático de Direito, impedir que o Estado **perdoe** (por ato de clemência) os atos praticados, seja por **lei federal** em que se conceda a **anistia** (em seu sentido mais amplo proposto e, pois, abrangendo os **crimes** e

infrações disciplinares conexas — art. 48, VIII, **não** se exigindo a iniciativa reservada ao Chefe do Executivo), **seja por lei estadual**, *cancelando (extinguindo) as infrações disciplinares (anistia administrativa)* e, assim, dispondo sobre os seus servidores, civis e militares (regime jurídico), **devendo, nesse caso da competência estadual, referida lei ser de iniciativa reservada dos Governadores de Estado** (já que o Estado não pode legislar sobre anistia — art. 21, XVII, sendo, então, o **fundamento** para a **clemência** outro, qual seja, os arts. 61, §, 1.º, II, “c” e “f”).

No sentido da necessidade de iniciativa reservada aos Governadores em âmbito estadual, vem se pronunciando o STF:

“EMENTA: (...) Lei estadual que concede ‘anistia’ administrativa a servidores públicos estaduais que interromperam suas atividades — paralisação da prestação de serviços públicos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que cabe ao **chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo** referente a lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem assim disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos. Aplica-se aos Estados-membros o disposto no art. 61, § 1.º, II, da CF. Precedentes. **Inviável o projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo que disponha a propósito servidores públicos — ‘anistia’ administrativa, nesta hipótese — implicando aumento de despesas para o Poder Executivo**” (ADI 341, Rel. Min. Eros Grau, j. 14.04.2010, Plenário, DJE de 11.06.2010).[47](#)

E, finalmente, estendendo a argumentação, além da perspectiva mais ampla do instituto da anistia, havendo decisão política no sentido da clemência (perdão), o ato poderia abranger não apenas os **crimes**, mas também as **infrações disciplinares conexas**, na medida em que, quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar (*vide*, nesse sentido, art. 14, § 1.º, do Dec. n. 4.346/2002, que *aprova o Regulamento Disciplinar do Exército — R 4 — e dá outras providências*).

Propomos, então, a esquematização da matéria:

a anistia (perdão, clemência) em relação a crimes, deverá ser por lei federal;

o ato político federal poderá dar um sentido mais amplo ao termo anistia, englobando também as infrações disciplinares conexas. No caso de lei federal e adotando o sentido amplo do “perdão”, não haverá afronta à regra da iniciativa reservada do Governador;

por sua vez, concorrentemente, as leis estaduais poderão conceder a anistia administrativa aos servidores estaduais (não por crimes). Nesse caso, a iniciativa do projeto de lei terá que ser do Governador do Estado, pois disciplinará sobre o regime jurídico dos servidores estaduais.

Essa parece ser uma solução em relação às leis que concedem a anistia, seja para os supostos crimes, seja para as infrações disciplinares conexas decorrentes de participação em movimentos reivindicatórios (**matéria pendente** de definição pelo STF no julgamento das ADIs 4.377 e 4.869).

■ 13.7.10. Polícias dos Municípios

Os Municípios poderão constituir **guardas municipais** destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, **conforme dispuser a lei** (art. 144, § 8.º).

Regulamentando a Constituição, a **Lei n. 13.022/2014** dispôs sobre o **Estatuto Geral das Guardas Municipais** e está sendo questionada no STF na **ADI 5.156**, ajuizada em 20.08.2014 e ainda pendente de julgamento.

Se superada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, duas questões serão enfrentadas pelo STF: a) a lei indicada no art. 144, § 8.º, é lei federal ou se refere à lei de cada município, à luz do interesse local (discussão sobre suposto vício formal)?; b) em sendo lei federal, as regras fixadas no estatuto extrapolam ou não a “vocação constitucional específica” das guardas municipais, de proteção de bens, serviços e instalações dos Municípios?

Como bem anotou José Afonso da Silva, “os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que,

sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, **não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária**. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir *Guardas Municipais* destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança pública: assegurar a **incolumidade do patrimônio municipal**, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, **mas não é de polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar**. Por certo que **não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais**, que a Constituição atribui com **exclusividade à Polícia Civil** (art. 144, § 4.º), sem possibilidade de delegação às Guardas Municipais”.[48](#)

Em nosso entender, a lei indicada no art. 144, § 8.º, deve ser entendida como lei federal a estabelecer as diretrizes, as disposições e normas gerais. Isso porque, a instituição, em si, das Guardas Municipais dar-se-á por **lei específica de cada Município**, conforme, inclusive, deixa claro o art. 6.º do *Estatuto da Guarda Municipal*.

Em relação às competências (geral e específicas) previstas no art. 5.º do estatuto, a sua interpretação deverá sempre levar em conta os parâmetros constitucionais de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Por isso, parece ter razão o parecer da PGR que sustenta a inconstitucionalidade dos incisos VI, XIII e XVII do art. 5.º da Lei n. 13.022/2014 (atribuem às guardas municipais, em caráter primário, exercício de competências municipais de trânsito; atendimento de ocorrências emergenciais ou de pronto atendimento; auxílio na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades e dignitários).

Conforme vimos, as guardas municipais estão destituídas de competência para realização do policiamento ostensivo e preventivo, bem como para a apuração de infrações penais. Em relação às competências de trânsito, apenas entendemos possíveis aquelas que possam ter alguma relação com a proteção de bens, serviços e instalações. Fora essa hipótese, haverá violação à Constituição.

A definição do alcance preciso da regra contida no art. 144, § 8.º, CF/88, será

dada pelo STF no julgamento da citada [ADI 5.156](#) e no [RE 608.588](#), com repercussão geral reconhecida. Sobre a competência da guarda municipal para lavrar auto de infração de trânsito, o tema está posto no [RE 658.570](#) (repercussão geral), todos pendentes de julgamento.

■ 13.7.11. Segurança viária. Carreira dos agentes de trânsito. EC n. 82/2014

■ 13.7.11.1. Tramitação da EC n. 82/2014

A [EC n. 82/2014](#) é fruto da aprovação da PEC n. 55/2011-CD que, no Senado Federal, tramitou como PEC n. 77/2013.

Em seu texto original, a PEC n. 55/2011, apresentada por 177 Deputados Federais, sob a liderança do Deputado Hugo Motta, dava nova redação ao parágrafo 8.º do art. 144 para disciplinar a carreira dos *agentes de fiscalização e controle de trânsito* responsáveis pelo policiamento de trânsito em âmbito exclusivamente *municipal*.

A justificativa se dava em razão da inegável alocação dos Municípios como principais gestores do trânsito a partir do advento Código Brasileiro de Trânsito (CTB — Lei n. 9.503/97, destacando-se o seu art. 24).[49](#)

Contudo, na *Comissão Especial* destinada a emitir parecer sobre referida PEC, o Relator, Deputado Efraim Filho, concluiu ser necessário modificar **drasticamente** a proposta encaminhada, estabelecendo a competência também para os Estados-membros e o DF e ampliando a perspectiva da **segurança viária** não somente para **fiscalização** e **controle**, como, também, para **educação** e **engenharia de trânsito**.

Assim, foi apresentada **emenda substitutiva global** da referida PEC, contemplando as **duas** situações apontadas.

■ 13.7.11.2. A segurança viária é questão de saúde pública

■ 13.7.11.2. A segurança viária é questão de saúde pública

A **primeira alteração**, qual seja, a ampliação da competência para os Estados e o DF, além dos Municípios, é justificada por considerar a violência no trânsito questão de **saúde pública**.

A ONU, partindo de estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), editou, em 02.03.2010, a Res. n. 64/255 (*Improving global road safety*)⁵⁰ que define o período de 2011 a 2020 como a “**Década de Ações para a Segurança no Trânsito**”.

De acordo com os dados trazidos no parecer da Comissão Especial, a violência no trânsito é uma das maiores causas de mortes, principalmente entre os jovens. “De acordo com dados de 2011 do IBGE, no Brasil ocorrem 45 mil mortes/ano em consequência de acidentes de trânsito, e o Ministério da Saúde tem um gasto estimado em R\$ 200 milhões por internações decorrentes destes acidentes. O quadro preocupa a Previdência Social, que teme ter de arcar com os custos de uma geração de jovens aposentados por invalidez. O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) gasta atualmente mais de R\$ 8 bilhões por ano com as despesas decorrentes de acidentes de trânsito no país”.

Portanto, a **responsabilidade pela segurança viária**, conforme anotado na PEC e realidade com a **EC n. 82/2014**, deve ser **partilhada** entre os Estados, DF e Municípios, competindo aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, que deverão estar estruturados em carreira, na forma da lei.

Concordamos com Julyver Modesto de Araujo ao afirmar que a EC n. 82/2014 “falhou ao deixar de lado a menção aos órgãos e entidades da **União**, que igualmente **fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito** (cuja composição encontra-se no artigo 7.º do CTB);⁵¹ embora a Polícia Rodoviária Federal já conste do rol de órgãos de Segurança Pública (inciso II do *caput* do artigo 144 da CF), o fato é que existem competências atribuídas ao órgão ou entidade executivo rodoviário (artigo 21 do CTB), diretamente ligadas à **segurança viária**, como a fiscalização em rodovias federais, exercida pelo

(nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 289/2008)”. [52](#)

■ 13.7.11.3. *Tripé da segurança viária*

A **segunda alteração** estabeleceu com muita clareza o que podemos chamar de “**tripé da segurança viária**”. De acordo com o art. 144, § 10, CF/88, introduzido pela EC n. 82/2014, a **segurança viária**, exercida para a **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas**, compreende a **educação**, **engenharia** e **fiscalização de trânsito**, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à **mobilidade urbana eficiente**. Em razão dessa cláusula de encerramento com a indicação de “outras atividades previstas em lei”, trata-se de *standard* mínimo a ser observado:



Nesse sentido, como bem apresentado no Parecer n. 230/2014 da CCJ no Senado Federal, por seu Relator, o Senador Vital do Rêgo, “ao incluir a educação e a engenharia de trânsito, ao lado da fiscalização, no âmbito de atuação dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, a proposição adota **conceito atual e abrangente**, que favorecerá a **prevenção de acidentes e não apenas a punição de infratores**”.

■ 13.7.11.4. *Segurança viária: questão a ser tratada de forma indissociável da segurança pública*

De acordo com o introduzido art. 144, § 10, *caput*, a **segurança viária** deverá ser exercida para a **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas** e do seu **patrimônio** nas **vias públicas**.

Por estar inserida como parágrafo do art. 144, a segurança viária deverá ser tratada no **contexto** da **segurança pública**, estabelecida pela Constituição como dever do Estado, e não só direito, mas, também, **responsabilidade de todos**.

Nesse sentido, Julyver Modesto de Araujo reconhece a necessidade de **participação social** para o trânsito mais seguro. E continua: diferente do prescrito no art. 1.º, § 2.º, do Código de Trânsito Brasileiro — Lei n. 9.503/97 (“o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e **dever** dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”), a segurança viária, dever do Estado, é direito e, também, **responsabilidade de todos**. [53](#)

■ 13.7.11.5. *A carreira específica de agentes de trânsito*

Outra novidade introduzida pela EC n. 82/2014 foi a previsão, **ao lado dos respectivos órgãos ou entidades executivos**, da **Carreira específica de agentes de trânsito** a ser estruturada na forma da lei e em âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal, devendo o provimento no cargo se dar, necessariamente, por **concurso público**, na forma do art. 37, II, CF/88.

Com a nova regra, agora de modo muito claro, estão **vedadas** as hipóteses de **contratação por tempo determinado**, [54](#) bem como a **destinação de servidores públicos, para a segurança viária, provenientes de outros cargos ou carreiras** (e que exercem **função diversa**), o que caracterizaria o **combatido “desvio de função”** e, assim, afronta ao entendimento estabelecido pelo STF na S. 685, convertida na **SV 43**: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, **sem prévia aprovação em**

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” (j. 08.04.2015, *DJE* de 17.04.2015).

Ainda, em razão da emenda substitutiva global aprovada, conforme visto acima, também não se pode confundir a carreira específica de **agentes de trânsito** com a de **guardas municipais** que continuam destinados à proteção de bens, serviços e instalações dos Municípios, **conforme dispuser a lei** (art. 144, § 8.º).

A lei, no caso e conforme visto, é a de número **13.022/2014**, que dispôs sobre o **Estatuto Geral das Guardas Municipais** e cujo art. 5.º, VI, estabeleceu ser **competência específica** das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, exercer as **competências de trânsito** que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal.

Teremos que aguardar a posição a ser firmada pelo STF. Em nossa opinião, contudo, não podemos admitir que essa competência de trânsito extrapole a destinação primordial das guardas municipais, qual seja, a proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios (pendente de análise — ADI 5.156 — cf. *item 13.7.10*).

Finalmente, entendemos que a nova **carreira específica de agentes de trânsito** criada pela EC n. 82/2014 não afastará a atividade de **policciamento ostensivo de trânsito** que já vem sendo implementada pela **polícia militar** e com muita eficiência. Vejam que o art. 144, § 10, II, introduzido, trata da nova carreira de agentes de trânsito **ao lado e sem a substituição** dos respectivos **órgãos ou entidades executivos**. [55](#)

■ 13.8. QUESTÕES

1. (OAB/100.º) Na vigência do estado de sítio só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, exceto:

- a) obrigação de permanência em localidade determinada e detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
- b) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, inclusive restrições a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas mesmo que liberada pela respectiva Mesa;
- c) suspensão da liberdade de reunião e busca e apreensão em domicílio;
- d) intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens.

2. (TJ/PA/2002) Tanto o estado de defesa como o estado de sítio são situações de excepcionalidade política que não se devem perpetuar no tempo, sob pena de quebra da democracia, pois em sua vigência são admitidas restrições a direitos fundamentais. A respeito desse tema, julgue os itens abaixo:

- 1. na hipótese de vigência de estado de sítio motivado por grave instabilidade político-econômica interna, ameaçadora da paz social e do funcionamento das instituições públicas e privadas, poderá ser excluída da apreciação pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos individuais ou coletivos.
- 2. durante o estado de sítio ou o estado de defesa, a Constituição da República não pode ser alterada, e o Congresso Nacional não pode ser impedido de funcionar.
- 3. fora do estado de flagrância, na vigência do estado de defesa ou de sítio, em nenhuma hipótese a prisão de qualquer pessoa pode ser determinada por outra autoridade que não a judicial.
- 4. em caso de declaração de guerra em que o Brasil esteja envolvido, cabe a decretação do estado de defesa e não do estado de sítio.
- 5. as imunidades parlamentares ficam automaticamente suspensas durante o estado de sítio.

3. (OAB/113.º) O Município está constitucionalmente autorizado a criar guarda municipal com objetivo de:

- a) suplementar eventual omissão do Estado em matéria de segurança pública;
- b) colaborar com a polícia civil na função de polícia judiciária;
- c) proteger bens, serviços e instalações do Município;
- d) auxiliar na preservação da ordem pública no âmbito de seu território.

4. (MP/SP 178.º — 2006) De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública

é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, cabendo, o seu exercício, através

- I. da polícia rodoviária federal;
- II. da polícia ferroviária federal;
- III. das polícias militares;
- IV. dos corpos de bombeiros militares.

Está integralmente correto o contido em

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

5. (MP/TO/2006/CESPE/UnB) No referente à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta:

- a) Os mecanismos de defesa da Constituição não estão sujeitos a controle de prazo, pois podem vigorar de acordo com apreciação discricionária do presidente da República.
- b) A Constituição de 1988 determina que a polícia federal é a polícia judiciária da União, razão pela qual apenas ela pode investigar fatos que constituam delitos contra o poder público federal, conforme entendimento já firmado pelos tribunais superiores.
- c) Com as últimas reformas da Constituição, os militares adquiriram o direito de sindicalizar-se, mas não podem participar de reuniões fora do serviço portando armas.
- d) A fixação dos pressupostos e requisitos de validade para a decretação dos chamados estados constitucionais de emergência somente pode ser feita pela própria Constituição, não por normas infraconstitucionais.

6. (MPT/2007) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. No estado de defesa para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, é possível a restrição temporária aos direitos de reunião, sigilo de correspondência e de comunicação telegráfica e telefônica.
- II. Na vigência do estado de sítio, não se admitem restrições à liberdade de ir e vir nem à inviolabilidade de correspondência.
- III. Aos militares asseguram-se, entre outros direitos, o gozo de férias anuais remuneradas,

- II. Na vigência do estado de sítio, não se admitem restrições à liberdade de ir e vir nem à inviolabilidade de correspondência.
 - III. Aos militares asseguram-se, entre outros direitos, o gozo de férias anuais remuneradas, com acréscimo de 1/3, e licença-gestante de 120 dias.
 - IV. As funções de polícia judiciária da União são exercidas, com exclusividade, pela polícia federal.
- a) apenas os itens I e II são corretos;
 - b) apenas os itens II e IV são corretos;
 - c) apenas os itens I, III e IV são corretos;
 - d) apenas os itens III e IV são corretos;
 - e) não respondida.

7. (TJ/DF/2007) Sobre Segurança Pública, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar:

- a) Compete à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
- b) Os corpos de bombeiros militares são órgãos de segurança pública e não executam atividades de defesa civil;
- c) Às polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares;
- d) Os Municípios não poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus serviços.

8. (Delegado de Polícia/SC-ACAFE-2008) Quanto ao estado de defesa e estado de sítio, analise as afirmações a seguir.

- I. O Presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar estado de sítio para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por grandes calamidades.
- II. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, sendo, por exemplo, admitida restrição aos direitos de

públicos e requisição de bens.

- IV. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por sessenta dias, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Estão corretas apenas:

- a) II e III;
- b) I e III;
- c) I e IV;
- d) I e II.

9. (TJ/AL/UnB/CESPE-2008) Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta:

- a) As imunidades dos deputados federais e dos senadores previstas na CF subsistirão mesmo no estado de sítio, não havendo possibilidade de sua suspensão.
- b) O estado de defesa autoriza a convocação extraordinária do Congresso Nacional pelo presidente da República.
- c) A emenda à CF, mesmo na hipótese de estado de defesa ou de estado de sítio, necessita de maioria e carece, para sua aprovação, de votação em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
- d) O estado de defesa autoriza a restrição ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, ao sigilo de correspondência e ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.
- e) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive eleitorais e militares.

10. (Magistratura-TJ/SC 2009) De acordo com o texto constitucional, assinale a alternativa correta quanto a estado de defesa e estado de sítio:

- I. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

- II. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.
- III. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente da Câmara dos Deputados, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.
- a) Somente as proposições I e II estão corretas.
- b) Somente as proposições I e II estão incorretas.
- c) Todas as proposições estão corretas.
- d) Somente a proposição I está correta.
- e) Todas as proposições estão incorretas.

11. (Oficial da Defensoria Pública do Estado de SP/FCC/2010) A ocorrência de calamidade de graves proporções na natureza possibilita ao Presidente da República decretar, nos termos da Constituição Federal:

- a) estado de calamidade pública.
- b) estado de sítio, ouvido previamente o Tribunal de Justiça.
- c) estado de defesa.
- d) intervenção federal.
- e) intervenção de ordem pública.

12. (Promotor de Justiça/SE — CESPE/UnB — 2010) Com relação à segurança pública, à polícia ostensiva e à polícia judiciária, assinale a opção correta.

- a) A segurança pública é dever da União e tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
- b) Os municípios que tiverem mais de vinte mil habitantes podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.
- c) Às polícias civis competem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- d) Compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico e garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, bem como sobre normas de organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
- e) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se aos governadores

dos estados, com exceção do DF, onde a subordinação se dá em relação ao chefe de governo da União.

13. (Perito Criminal — PC-ES — CESPE/UnB/2011) No tocante ao tema da segurança pública e sua organização, julgue o item seguinte:

Sendo a segurança um dever estatal, direito e responsabilidade de todos, os municípios, em momentos de instabilidade social, podem constituir guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública.

14. (Analista Jurídico — PG-DF — IADES/2011) O sistema constitucional tem de prever mecanismos para que o Estado possa agir, ainda que excepcionalmente, em estados de crise. Há de se submeter o Estado, mesmo nessas situações, a condições impostas pela Constituição. Em relação aos instrumentos previstos na Constituição Federal brasileira, assinale a alternativa correta:

- a) É requisito indispensável para a decretação dos regimes de estado de defesa e de sítio a prévia solicitação de autorização feita pelo Presidente da República dirigida ao Congresso Nacional, que somente será concedida se aprovada pela maioria absoluta de seus membros.
- b) Os regimes de estado de defesa e de sítio são estatuídos por Decreto do Presidente da República, do que, vinculadamente, deve observar a manifestação dos Conselhos da República e de Defesa Nacional.
- c) Observados os procedimentos constitucionais, é possível a decretação do estado de sítio com a suspensão de qualquer garantia constitucional.
- d) A duração da decretação do estado de sítio deve ser, no máximo, de 30 (trinta) dias, prorrogáveis, após a aprovação do Congresso Nacional, por até igual período.
- e) Os eventuais abusos cometidos durante a execução do estado de defesa e de sítio deverão ser julgados pelo Judiciário, com a responsabilização dos agentes e do próprio Estado, se for o caso; todavia, esse controle judicial somente poderá ocorrer após a cessação dos regimes de exceção.

15. (Delegado de Polícia — PC/MG/2011) Quanto aos sistemas estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, para enfrentar os períodos de crise política nos quais a ordem constitucional se vê ameaçada, estão previstos:

- a) o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção federal e o uso excepcional das forças armadas.

- b) a suspensão da Constituição, a lei marcial, o estado de defesa, o estado de sítio e a suspensão do *habeas corpus*.
- c) a supressão dos direitos fundamentais, entre eles, a inviolabilidade de domicílio e de correspondência.
- d) a vedação quanto à impetração do mandado de segurança, do mandado de injunção, do *habeas corpus* e do *habeas data*.

16. (Técnico Judiciário — TRE/PE — Área Administrativa — FCC/2011) No caso de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo:

- a) Ministro das Forças Armadas.
- b) Presidente da Câmara dos Deputados.
- c) Presidente do Senado Federal.
- d) Ministro Chefe da Casa Civil.
- e) Ministro da Justiça.

17. (Procurador da AL-ES — CESPE/UnB/2011) Assinale a opção correta quanto à defesa do Estado e das instituições democráticas:

- a) A natureza discricionária do ato do presidente da República que decreta o estado de sítio não viabiliza o controle judicial, razão pela qual há, sobre tal ato, a incidência do controle exclusivamente político, exercido pelo Congresso Nacional.
- b) Não se admite, no estado de defesa e no estado de sítio, a suspensão das denominadas imunidades parlamentares.
- c) Os estados-membros podem, a seu critério, inserir os seus respectivos departamentos de trânsito entre os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública.
- d) A punição disciplinar militar imposta sem que haja previsão legal é passível de impugnação via *habeas corpus*.
- e) Para a prorrogação do prazo de duração do estado de defesa é dispensável a aprovação do Congresso Nacional.

18. (Magistratura/SP — VUNESP/2011) Leia as afirmativas quanto à segurança pública. É correto apenas o que se afirma em:

- I. É exercida pela polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares.

- II. Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.
- III. Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
- IV. Compete à polícia federal exercer, em concorrência com as polícias civis estaduais, as funções de polícia judiciária da União.
- a) II, III e IV.
- b) I, III e IV.
- c) I e II.
- d) IV.
- e) I, II e III.

19. (Analista Judiciário — TRT/11 — FCC/2012) Gustavo, Presidente da República, após ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretou estado de defesa para preservar, em local restrito e determinado, a ordem pública ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, indicando no decreto, segundo a Constituição Federal, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, podendo restringir os direitos de:

- a) ir e vir, sujeito à pena de banimento, apenas.
- b) ir e vir, sujeito à prisão perpétua e multa.
- c) imagem e de propriedade intelectual.
- d) reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.
- e) livre manifestação do pensamento e de propriedade imóvel.

20. (PRF — Agente Administrativo — CESPE/UnB/2012) Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir:

À PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais.

21. (PRF — Agente Administrativo — CESPE/UnB/2012) Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir:

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária.

constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir:

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária.

22. (Delegado de Polícia/AL — CESPE/UnB/2012) Em relação às normas constitucionais relativas à segurança pública, julgue o próximo item:

Os corpos de bombeiros militares e as polícias militares são forças auxiliares do Exército, não se subordinando aos governadores de estado.

23. (Magistratura/CE — CESPE/UnB/2012) Assinale a opção correta acerca dos preceitos relativos à defesa do Estado e das instituições democráticas:

- a) No estado de defesa e no estado de sítio, as imunidades parlamentares não podem ser suspensas.
- b) O estado de sítio não pode ser decretado apenas para determinada área específica, considerando-se sua abrangência nacional.
- c) Embora a decretação do estado de defesa submeta-se à aprovação da maioria absoluta do Congresso Nacional, sua prorrogação dispensa tal providência, sendo suficiente ato do chefe do Poder Executivo demonstrando a necessidade de estender a medida por igual período.
- d) As especificações da amplitude do estado de sítio podem ser feitas após a sua decretação.
- e) Considerada a excepcionalidade da medida, o controle judicial do estado de defesa abrange o juízo de conveniência e oportunidade quanto à prática do ato.

24. (Juiz Federal — 5.^a Região — CESPE/UnB/2013) Com relação à segurança pública, defesa do estado e das instituições democráticas e funções essenciais à justiça, assinale a opção correta:

- a) O decreto que instituir o estado de defesa pode indicar, como medida coercitiva, a busca e apreensão em domicílio.
- b) É constitucional, de acordo com entendimento do STF, norma estadual que atribua à defensoria pública estadual a prestação de assistência judicial a servidores públicos processados pela prática de ato em razão do exercício de suas funções.
- c) É obrigatória a participação do Poder Legislativo estadual no procedimento de escolha e nomeação do Procurador-geral de justiça de Estado-membro, assim como é obrigatória a participação do Senado Federal no procedimento de escolha e nomeação do

constitucionalmente, é taxativo e, segundo o STF, os Estados-membros e o DF devem observá-lo.

25. (Agente Penitenciário Federal — DEPEN — CESPE/UnB/2013) Com referência à administração pública e seus agentes, julgue o item subsequente:

Com relação à greve no serviço público, o STF tem decidido aplicar a legislação existente para o setor privado aos servidores públicos. Entretanto, em razão da índole de suas atividades públicas, o STF decidiu pela inaplicabilidade do direito de greve a certos servidores, como os que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública, à segurança pública e à administração da justiça.

■ **GABARITO** ■

1. “b”. Cf. art. 139, I a VII, combinado com o parágrafo único do art. 139.
2. 1-E (art. 5.º, XXXV — tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição); 2-C (arts. 60, § 1.º; 136, § 6.º; e 138, § 3.º); 3-E (art. 136, § 3.º, I e III); 4-E (art. 137, II); 5-E (art. 53, § 8.º).
3. “c”. Cf. art. 144, § 8.º, da CF.
4. “d”, já que utilizou a expressão “segurança pública” de modo amplo.
5. “d”.
6. “c”. Art. 136, § 1.º, I, “a”, “b”, “c”; art. 139, I e III; art. 142, § 3.º, VIII; art. 144, § 1.º, IV.
7. “a”. Art. 144, § 1.º, II, da CF/88.
8. “a”. Arts. 136, § 1.º, I, “a”, e 139, V, VI e VII, da CF/88. O item “I” está errado, pois traz hipótese de estado de defesa (art. 136, <i>caput</i>), e o item “IV” está errado já que a prorrogação do estado de defesa será, uma única vez, por 30 dias (art. 136, § 2.º).
9. “d”. Art. 136, § 1.º, “a” e “c”, da CF/88. A letra “a” está errada por violar o art. 53, § 8.º. A letra “b” fere o art. 57, § 6.º, I (convocação pelo Presidente do SF). A letra “c” está errada porque a CF não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou estado de sítio, além da intervenção federal (art. 60, § 1.º). A letra “e” está errada por violar o art. 144, § 4.º.

10. “a”. Arts. 136, <i>caput</i> , e 137, parágrafo único. O item III está errado, pois, durante o recesso parlamentar, a convocação extraordinária para a hipótese deverá ser implementada pelo Presidente do SF, e não da CD, conforme está na questão (art. 57, § 6.º, I).
11. “c”.
12. “c”.
13. “errado”.
14. “c”, conforme o art. 138, <i>caput</i> , c/c o art. 137, II, da CF/88.
15. “a”.
16. “c”, nos termos do art. 57, § 6.º, I.
17. “d”.
18. “e”.
19. “d”, conforme a literalidade do art. 136, § 1.º, I, “a”-“c”.
20. “errado”. De acordo com o art. 144, § 2.º, da CF/88, a polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, apenas, e não das estaduais.
21. “errado”. De acordo com o art. 144, § 1.º, IV, da CF/88, a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
22. “errado”. Nos termos do art. 144, § 6.º, da CF/88, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
23. “d”, cf. art. 138, <i>caput</i> , e parte teórica. A letra “a” está errada por violar o art. 53, § 8.º. A letra “b” está errada, pois, apesar do caráter nacional da comoção grave, nos termos do art. 138, <i>caput</i> , depois de publicado o decreto o Presidente da República especificará as áreas abrangidas (<i>vide</i> parte teórica). A letra “c” viola o art. 136, § 4.º, que estabelece o controle político também

na hipótese de prorrogação. A *letra “e”* está errada por se tratar de mérito administrativo (com as observações feitas na parte teórica, cf. *item 13.2.3*).

24. “e”.

25. “certo”, cf. *item 13.7.9.1*.

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

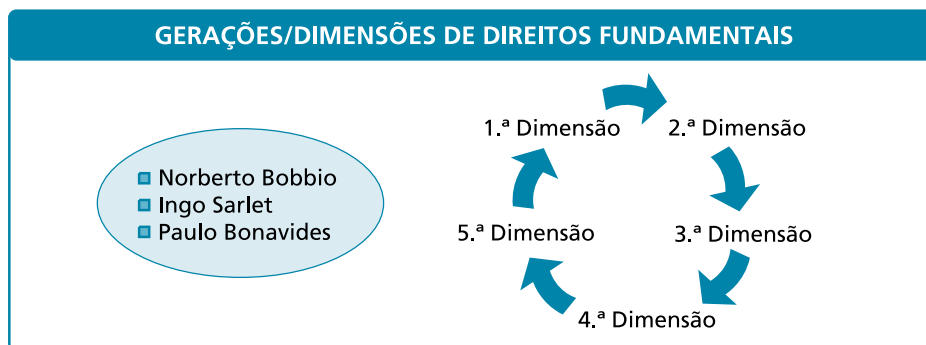
■ 14.1. LOCALIZAÇÃO

A CF/88, em seu título II, classifica o gênero **direitos e garantias fundamentais** em importantes grupos, a saber:

- direitos e deveres individuais e coletivos;
- direitos sociais;
- direitos de nacionalidade;
- direitos políticos;
- partidos políticos.

Iniciamos o estudo pelos **direitos e deveres individuais e coletivos**, lembrando, desde já, como manifestou o STF, corroborando a doutrina mais atualizada, que os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem ao art. 5.º da CF/88, podendo ser encontrados ao longo do texto constitucional, [1](#) expressos ou decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, ou, ainda, decorrentes dos tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja parte.

■ 14.2. EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (“GERAÇÕES” OU “DIMENSÕES” DE DIREITOS)



Dentre vários critérios, costuma-se classificar os direitos fundamentais em **gerações de direitos**, ou, como prefere a doutrina mais atual, “**dimensões**” dos direitos fundamentais, por entender que uma nova “dimensão” não abandonaria as conquistas da “dimensão” anterior e, assim, esta expressão se mostraria mais adequada no sentido de proibição de evolução reacionária.

Em um primeiro momento, partindo dos lemas da *Revolução Francesa* — **liberdade, igualdade e fraternidade**, anunciavam-se os direitos de 1.ª, 2.ª e 3.ª dimensão e que iriam evoluir segundo a doutrina para uma 4.ª e 5.ª dimensão.

■ 14.2.1. Direitos fundamentais da 1.ª dimensão

Os **direitos humanos da 1.ª dimensão** marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às **liberdades individuais**, em uma verdadeira perspectiva de absentéismo estatal.

Seu reconhecimento surge com maior evidência nas primeiras Constituições escritas, e podem ser caracterizados como frutos do pensamento liberal-burguês do século XVIII.

Tais direitos dizem respeito às **liberdades públicas** e aos **direitos políticos**, ou seja, **direitos civis e políticos** a traduzir o valor **liberdade**.

Conforme anota Bonavides, “os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades têm por titular o **indivíduo**, são **oponíveis** ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são **direitos de resistência** ou de **oposição** perante o Estado”.²

Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência do que os autores chamam de direitos humanos de 1.^a geração (séculos XVII, XVIII e XIX), destacando-se:

- **Magna Carta de 1215**, assinada pelo rei “João Sem terra”;
- **Paz de Westfália** (1648);
- **Habeas Corpus Act** (1679);
- **Bill of Rights** (1688);
- **Declarações**, seja a **americana** (1776), seja a **francesa** (1789).

Finalmente, cabe alertar o reconhecimento, por parte da doutrina, de certo conteúdo social no constitucionalismo francês, como anota Ingo Sarlet.³

Nesse sentido, Dimoulis e Martins chegam a afirmar que o termo “geração” não se mostra cronologicamente exato porque já se observavam nas primeiras Constituições e Declarações dos séculos XVIII e XIX certos direitos sociais. Ao tratar da *Declaração francesa*, destacam a “... garantia à assistência aos necessitados como uma ‘dívida sagrada’ da sociedade e o direito de acesso à educação (arts. 21 e 22). E a Constituição brasileira do Império de 1824 incluía entre os direitos fundamentais dois direitos sociais, os ‘socorros públicos’ e a ‘instrução primária’ gratuita (art. 179, XXXI e XXXII), ambos direitos sociais e diretamente inspirados na Declaração francesa...”.⁴

■ 14.2.2. Direitos fundamentais da 2.^a dimensão

O fato histórico que inspira e impulsiona os **direitos humanos de 2.^a dimensão** é a **Revolução Industrial europeia**, a partir do século XIX.

Em decorrência das péssimas situações e condições de trabalho, eclodem movimentos como o **cartista, na Inglaterra**, e a **Comuna de Paris (1848)**, na busca de reivindicações trabalhistas e normas de assistência social.

O início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra e pela fixação de **direitos sociais**.

Essa perspectiva de evidenciação dos **direitos sociais, culturais e econômicos**, bem como dos **direitos coletivos**, ou de **coletividade**, correspondendo aos direitos de **igualdade** (substancial, real e material, e não meramente formal), mostra-se marcante em alguns documentos, destacando-se:

- Constituição do **México**, de 1917;
- Constituição de **Weimar**, de 1919, na Alemanha, conhecida como a *Constituição da primeira república alemã*;
- **Tratado de Versalhes**, 1919 (OIT);
- no Brasil, a **Constituição de 1934** (lembrando que nos textos anteriores também havia alguma previsão).

Bonavides observa que essas Constituições “passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos” (aquilo que hoje se fala em **“reserva do possível”**, acrescente-se).

E continua o mestre: “de juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada esfera programática, em virtude de não conterem para sua concretização aquelas garantias habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais de proteção aos direitos da liberdade. Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e execução, cujo fim parece estar perto, desde que recentes Constituições, inclusive a do Brasil, formularam o preceito de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais”.⁵

■ 14.2.3. Direitos fundamentais da 3.^a dimensão

Os **direitos fundamentais da 3.^a dimensão** são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico e científico), identificando-se profundas alterações nas relações econômico-sociais.

Novos problemas e preocupações mundiais surgem, tais como a necessária

noção de **preservacionismo ambiental e as dificuldades para proteção dos consumidores**, só para lembrar aqui dois candentes temas. **O ser humano é inserido em uma coletividade e passa a ter direitos de solidariedade ou fraternidade.**⁶

Os direitos da 3.^a dimensão são direitos transindividuais, isto é, direitos que vão além dos interesses do indivíduo; pois são concernentes à proteção do **gênero humano**, com altíssimo teor de **humanismo e universalidade**.

Segundo Bonavides,⁷ a teoria de **Karel Vasak** identificou, em rol exemplificativo, os seguintes direitos de 3.^a dimensão:

- direito ao **desenvolvimento**;
- direito à **paz** (lembrando que Bonavides classifica, atualmente, o direito à paz como da **5.^a dimensão** — cf. *item 14.2.5*);
- direito ao **meio ambiente**;
- direito de **propriedade** sobre o **patrimônio comum da humanidade**;
- direito de **comunicação**.

■ 14.2.4. Direitos fundamentais da 4.^a dimensão

Na orientação de **Norberto Bobbio**, essa dimensão de direitos decorreria dos avanços no campo da **engenharia genética**, ao colocarem em risco a própria existência humana, em razão da manipulação do patrimônio genético. Para o mestre italiano: “... já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de **quarta geração**, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo”.⁸

Por outro lado, **Bonavides** afirma que “a **globalização política** na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da **quarta dimensão**, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social”, destacando-se os direitos a:

■ **democracia** (direta);

■ **informação**;

■ **pluralismo**.

Assim, para Bonavides, os direitos da 4.^a dimensão decorrem da **globalização dos direitos fundamentais**, o que significa **universalizá-los** no **campo institucional**.

Ingo Sarlet afirma que “a proposta do Prof. Bonavides, comparada com as posições que arrolam os direitos contra a manipulação genética, mudança de sexo etc., como integrando a quarta geração, oferece nítida vantagem de constituir, de fato, uma nova fase no reconhecimento dos direitos fundamentais, qualitativamente diversa das anteriores, já que não se cuida apenas de vestir com roupagem nova reivindicações deduzidas, em sua maior parte, dos clássicos direitos de liberdade”.⁹

■ 14.2.5. Direitos fundamentais da 5.^a dimensão

Conforme já dissemos, o **direito à paz** foi classificado por **Karel Vasak** como de 3.^a dimensão.

Bonavides, contudo, entende que o direito à paz deva ser tratado em dimensão autônoma, chegando a afirmar que a paz é axioma da **democracia participativa**, ou, ainda, **supremo direito da humanidade**.¹⁰

■ 14.3. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

O art. 5.^o, como vimos, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie do gênero direitos e garantias fundamentais (Título II). Assim, apesar de referir-se, de modo expresso, apenas a direitos e deveres, também consagrou as garantias fundamentais. Resta diferenciá-los.

Um dos primeiros estudiosos a enfrentar esse tormentoso tema foi o sempre

lembrado Rui Barbosa, que, analisando a Constituição de 1891, distinguiu “as disposições meramente *declaratórias*, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições *assecuratórias*, que são as que, em defesa dos *direitos*, limitam o poder. Aquelas instituem os *direitos*, estas as *garantias*; ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da garantia, com a declaração do direito”.¹¹

Assim, os **direitos** são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as **garantias** são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados.

Já a diferença entre **garantias fundamentais** e **remédios constitucionais** é que estes últimos são espécie do gênero garantia. Isso porque, uma vez consagrado o direito, a sua garantia nem sempre estará nas regras definidas constitucionalmente como remédios constitucionais (ex.: *habeas corpus*, *habeas data* etc.). Em determinadas situações a garantia poderá estar na própria norma que assegura o direito. Vejamos dois exemplos:

■ é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre-exercício dos cultos religiosos — art. 5.º, VI (**direito**), garantindo-se na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias (**garantia**);

■ direito ao juízo natural (**direito**) — o art. 5.º, XXXVII, veda a instituição de juízo ou tribunal de exceção (**garantia**).

■ 14.4. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Lembrando breve caracterização feita por David Araujo e Serrano Nunes Júnior,¹² os direitos fundamentais têm as seguintes características:

■ **historicidade**: possuem caráter histórico, nascendo com o cristianismo, passando pelas diversas revoluções e chegando aos dias atuais;

■ **universalidade**: destinam-se, de modo indiscriminado, a todos os seres humanos. Como aponta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “... a ideia de se

estabelecer por escrito um rol de direitos em favor de indivíduos, de direitos que seriam superiores ao próprio poder que os concedeu ou reconheceu, não é nova. Os **forais**, as **cartas de franquia** continham enumeração de direitos com esse caráter já na Idade Média...”;[13](#)

FORAIS/CARTAS DE FRANQUIA	DECLARAÇÕES DE DIREITOS
■ Voltam-se para determinadas categorias ou grupos particularizados de homens. ■ Reconhecem direitos a alguns homens por serem de tal corporação ou pertencerem a tal valorosa cidade.	■ Destinam-se ao homem, ao cidadão, em abstrato. ■ Reconhecem direitos a todos os homens por serem homens — em razão da natureza.

■ **limitabilidade:** os direitos fundamentais não são absolutos (**relatividade**), havendo, muitas vezes, no caso concreto, confronto, conflito de interesses. A solução ou vem discriminada na própria Constituição (ex.: direito de propriedade *versus* desapropriação), ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da **máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos**, conjugando-a com a sua **mínima restrição**;

■ **concorrência:** podem ser exercidos cumulativamente, quando, por exemplo, o jornalista transmite uma notícia (direito de informação) e, ao mesmo tempo, emite uma opinião (direito de opinião);

■ **irrenunciabilidade:** o que pode ocorrer é o seu não exercício, mas nunca a sua renunciabilidade.

José Afonso da Silva ainda aponta as seguintes características:[14](#)

■ **inalienabilidade:** como são conferidos a todos, são indisponíveis; não se pode aliená-los por não terem conteúdo econômico-patrimonial;

■ **imprescritibilidade:** “... prescrição é um instituto jurídico que somente

atinge, coarctando, a exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade dos direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição”.

■ 14.5. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

O art. 5.º, *caput*, da CF/88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos **brasileiros** e aos **estrangeiros residentes no País** a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos dos seus 78 incisos e parágrafos. Trata-se de um rol meramente **exemplificativo**, na medida em que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (§ 2.º).

Esse tema ganha bastante relevância com o § 3.º do art. 5.º da CF/88, acrescentado pela **EC n. 45/2004** e que foi muito discutido nos *itens* 6.7.1.2.7 e 9.14.5.2.2, aos quais remetemos o leitor (Art. 5.º, § 3.º — “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”).

O *caput* do art. 5.º faz referência expressa somente a brasileiros (natos ou naturalizados, já que não os diferencia) e a estrangeiros residentes no País. Contudo, a esses destinatários expressos, a doutrina e o STF vêm acrescentando, mediante interpretação sistemática, os estrangeiros não residentes (por exemplo, turistas), os apátridas e as pessoas jurídicas.

Nada impediria, portanto, que um estrangeiro, de passagem pelo território nacional, ilegalmente preso, impetrasse *habeas corpus* (art. 5.º, LXVIII) para proteger o seu direito de ir e vir. Deve-se observar, é claro, se o direito garantido não possui alguma especificidade, como ação popular, que só pode ser proposta pelo **cidadão**.

■ 14.6. A APLICABILIDADE DAS NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Nos termos do art. 5.º, § 1.º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**.

Já estudamos no *item 5.8* que o termo “aplicação” **não** se confunde com “aplicabilidade”, na teoria de José Afonso da Silva, que classifica as normas de eficácia **plena** e **contida** como tendo “aplicabilidade” **direta** e **imediata**, e as de eficácia **limitada** como possuidoras de aplicabilidade **mediata** ou **indireta**.

Na lição de José Afonso da Silva, ter **aplicação imediata** significa que as normas constitucionais são “dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. A regra é que as normas definidoras de *direitos e garantias individuais* (direitos de 1.ª dimensão, acrescente-se) sejam de *aplicabilidade imediata*. Mas aquelas definidoras de *direitos sociais, culturais e econômicos* (direitos de 2.ª dimensão, acrescente-se) nem sempre o são, porque não raro dependem de providências ulteriores que lhes completem a eficácia e possibilitem sua aplicação”. [15](#)

Assim, “por regra, as normas que consubstanciam os *direitos fundamentais democráticos e individuais* são de *aplicabilidade imediata*, enquanto as que definem os *direitos sociais* tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma lei integradora, são de *eficácia limitada e aplicabilidade indireta*”. [16](#)

Como exemplo de norma definidora de direito e garantia fundamental que depende de lei, podemos citar o **direito de greve** dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, ou o da **aposentadoria especial**, garantido nos termos do art. 40, § 4.º.

Então, qual seria o sentido dessa regra inscrita no art. 5.º, § 1.º?

José Afonso da Silva explica: “*em primeiro lugar*, significa que elas são aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. *Em segundo lugar*, significa que o Poder Judiciário, sendo

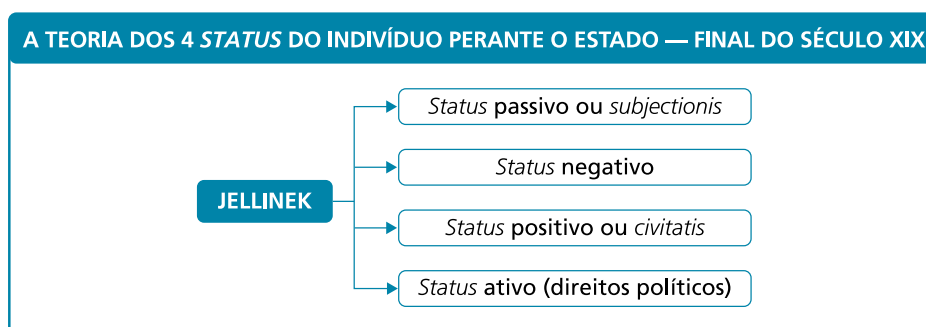
invocado a propósito de uma **situação concreta** nelas garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes”.¹⁷

Nesse sentido, diante de omissão de **medida** para tornar efetiva norma constitucional, a CF/88 trouxe duas importantes novidades, quais sejam, a **ação direta de inconstitucionalidade por omissão — ADO** (agora regulamentada na Lei n. 12.063, de 27.10.2009, e por nós comentada no *item 6.7.4*) e o **mandado de injunção** (MI — art. 5.º, LXXI, estudado no *item 14.11.5*).

Em relação a esses dois remédios para combater a “síndrome de inefetividade” das normas constitucionais de eficácia limitada, o STF tende a consolidar o entendimento de que, em se tratando de “Poder” omissivo na elaboração de medida para tornar efetiva a norma constitucional, a ADO restringiria-se a um mero apelo, constituindo-o em mora, enquanto o MI, por seu turno, seria o importante instrumento de **concretização** dos direitos fundamentais, como vem sendo percebido na jurisprudência do STF (cf. *item 14.11.5.4 e a relevante perspectiva trazida pela SV 33/2014*) e, assim, dando exato sentido ao art. 5.º, § 1.º, que fala em **aplicação imediata**.

■ 14.7. A TEORIA DOS QUATRO **STATUS** DE JELLINEK

Várias teorias tentam explicar o papel desempenhado pelos direitos fundamentais. Dentre outros estudos, destacamos a **teoria dos quatro status de Jellinek**, que, apesar de elaborada no final do século XIX, ainda se mostra muito atual.



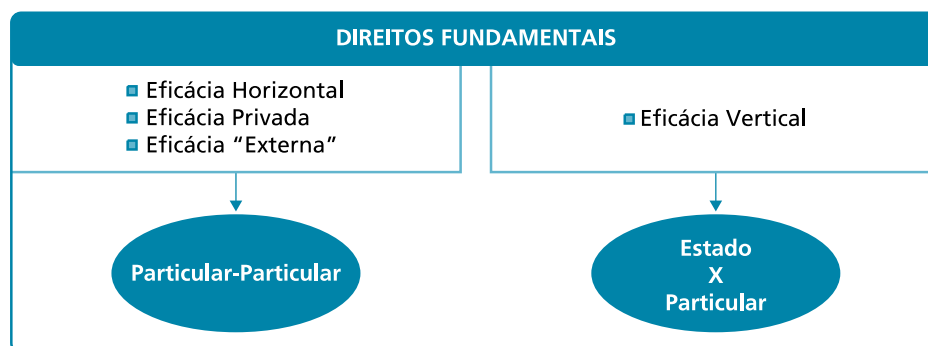
■ **status passivo ou *subjectionis***: o indivíduo se encontra em posição de subordinação aos poderes públicos, vinculando-se ao Estado por mandamentos e proibições. O indivíduo aparece como detentor de **deveres** perante o Estado;

■ **status negativo**: o indivíduo, por possuir personalidade, goza de um espaço de **liberdade** diante das ingerências dos Poderes Públicos. Nesse sentido, podemos dizer que a autoridade do Estado se exerce sobre homens livres;

■ **status positivo ou *status civitatis***: o indivíduo tem o direito de exigir que o Estado atue **positivamente**, realizando uma prestação a seu favor;

■ **status ativo**: o indivíduo possui competências para influenciar a formação da vontade do Estado, por exemplo, pelo exercício do direito do voto (exercício de **direitos políticos**).

■ 14.8. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS



■ 14.8.1. Aspectos gerais

O tema da **eficácia horizontal dos direitos fundamentais**, também denominado pela doutrina eficácia **privada** ou **externa** dos direitos fundamentais, surge como importante contraponto à ideia de eficácia **vertical** dos direitos fundamentais. [18](#)

A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre o particular e o Poder Público não se discute. Por exemplo, certamente, em um concurso

público deverá ser obedecido o princípio da isonomia.

Agora, por outro lado, será que nas relações privadas deve o princípio da isonomia ser obedecido?

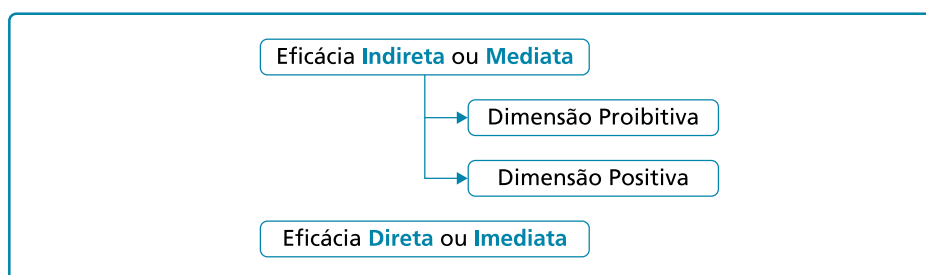
Damos um exemplo. Será que, em uma entrevista de emprego (na iniciativa privada), o dono do negócio deverá contratar o melhor candidato?

Será que o dono do negócio poderá demitir alguém simplesmente porque não está gostando de sua aparência?

É aí que surge o problema.

Algumas situações são fáceis de ser resolvidas. Sem dúvida, por exemplo, se um empresário demitir um funcionário em razão de sua “cor”, o Judiciário poderá (ou até “deverá”) reintegrar o funcionário, já que o ato motivador da demissão, além do triste e inaceitável crime praticado, fere, frontalmente, o princípio da **dignidade da pessoa humana**, fundamento da República Federativa do Brasil e **princípio-matriz** de todos os direitos fundamentais (art. 1.º, III, da CF/88).

■ 14.8.2. Teorias da eficácia indireta (mediata) ou direta (imediata)



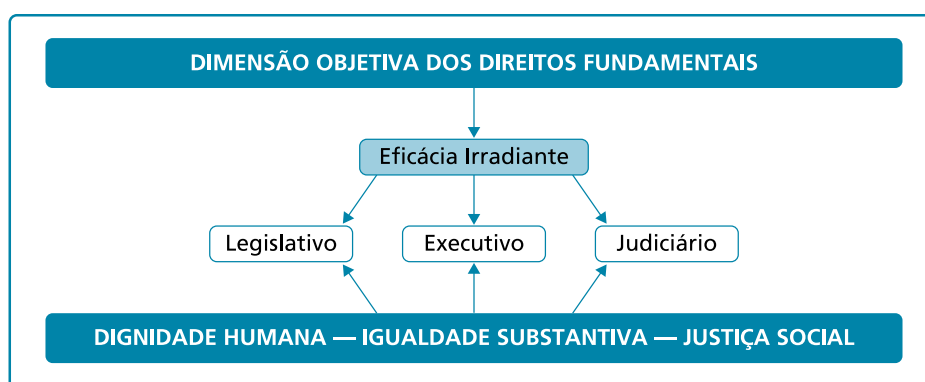
Nesse sentido, cogitando da aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, duas teorias podem ser destacadas: [19](#)

■ **eficácia indireta ou mediata:** os direitos fundamentais são aplicados de maneira reflexa, tanto em uma dimensão **proibitiva** e voltada para o legislador, que não poderá editar lei que viole direitos fundamentais, como, ainda, **positiva**, voltada para que o legislador implemente os direitos fundamentais, ponderando quais devam aplicar-se às relações privadas;

■ **eficácia direta ou imediata:** alguns direitos fundamentais podem ser aplicados às relações privadas sem que haja a necessidade de “intermediação legislativa” para a sua concretização.

■ 14.8.3. Eficácia “irradiante” dos direitos fundamentais

Podemos afirmar que importante consequência da **dimensão objetiva** dos direitos fundamentais é a sua “**eficácia irradiante**” (Daniel Sarmento), seja para o Legislativo ao elaborar a lei, seja para a Administração Pública ao “governar”, seja para o Judiciário ao resolver eventuais conflitos.



■ 14.8.4. Alguns precedentes

Abaixo, resumidamente, trazemos alguns precedentes em relação aos quais o Judiciário entendeu razoável a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas.

■ **RE 160.222-8:** entendeu-se constituir “constrangimento ilegal” a revista íntima em mulheres em fábrica de *lingerie*;

■ **RE 158.215-4:** entenderam-se violados o princípio do devido processo legal e o da ampla defesa na hipótese de exclusão de associado de cooperativa sem direito a defesa;

■ **RE 161.243-6:** discriminação de empregado brasileiro em relação ao francês na empresa “Air France”, mesmo realizando atividades idênticas. Determinação de observância do princípio da isonomia;

■ **RE 175.161-4:** contrato de consórcio que prevê devolução nominal de valor já pago em caso de desistência — violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (devido processo legal substantivo);

■ **HC 12.547/STJ:** prisão civil em contrato de alienação fiduciária em razão de aumento absurdo do valor contratado de R\$ 18.700,00 para R\$ 86.858,24. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (alertamos que o STF editou a **SV 25/2009:** “é **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”);

■ **REsp 249.321:** cláusula de indenização tarifada em caso de responsabilidade civil do transportador aéreo — violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

■ **RE 201.819:** exclusão de membro de sociedade sem a possibilidade de sua defesa — violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Gilmar Mendes).

Este último caso parece-nos ser o início de forte tendência que surge no âmbito do STF para a aplicação da teoria da **eficácia direta dos direitos fundamentais às relações privadas**.

Conforme voto do Ministro Gilmar Mendes, divergindo da relatora, Ministra Ellen Gracie, “esse caráter público ou geral da atividade parece decisivo aqui para **legitimar a aplicação direta dos direitos fundamentais** concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV, da CF) ao processo de exclusão de sócio de entidade”. [20](#)

■ 14.8.5. Brevíssima conclusão

COLISÃO		
■ Autonomia da vontade ■ Livre-iniciativa ■ Art. 1.º, IV ■ Art. 170, <i>caput</i>	X	■ Dignidade da pessoa humana ■ Máxima efetividade dos direitos fundamentais ■ Art. 1.º, III ■ Art. 5.º, § 1.º

Diante do exposto, sem dúvida, cresce a **teoria da aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas** (“eficácia horizontal”),

especialmente diante de atividades privadas que tenham certo “caráter público”, por exemplo, em escolas (matrículas), clubes associativos, relações de trabalho etc.

Nessa linha, poderá o magistrado deparar-se com inevitável colisão de direitos fundamentais: o princípio da **autonomia da vontade privada** e o da **livre-iniciativa** de um lado (arts. 1.º, IV, e 170, *caput*); o da **dignidade da pessoa humana** e o da **máxima efetividade dos direitos fundamentais** (art. 1.º, III) de outro.

Diante dessa “colisão”, indispensável será a “**ponderação de interesses**”²¹ à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. Não sendo possível a harmonização, o Judiciário terá de avaliar qual dos interesses deverá prevalecer.

■ 14.9. DEVERES FUNDAMENTAIS

Além dos *direitos fundamentais*, desenvolvem-se estudos sobre os **deveres fundamentais**, chegando alguns a sustentar uma nova “**Era dos Deveres Fundamentais**” (no Brasil, dentre outros, Carlos Rátis).

Dessa forma, diante da vida em sociedade, devemos pensar, também, a necessidade de serem observados os **deveres**, pois muitas vezes o **direito** de um indivíduo depende do **dever** do outro em não violar ou impedir a concretização do referido direito.

Dimoulis e Martins tratam do assunto, e procuraremos esquematizar o pensamento dos autores, identificando os seguintes **deveres fundamentais**:²²

■ **dever de efetivação dos direitos fundamentais**: sobretudo os *direitos sociais e garantias das instituições públicas e privadas*. Estamos diante da necessidade de atuação positiva do Estado, passando-se a falar em um Estado que tem o **dever** de realizar os direitos, aquela ideia de Estado prestacionista;

■ **deveres específicos do Estado diante dos indivíduos**: como exemplo, os autores citam o dever de indenizar o condenado por erro judiciário, o

que se dará por atuação e dever das autoridades estatais;

■ **deveres de criminalização do Estado:** a Constituição determina que o Poder Legislativo edite atos normativos para implementar os comandos, como no caso do art. 5.º, XLIII, devendo haver a normatização do crime de tortura;

■ **deveres dos cidadãos e da sociedade:** como exemplos, os autores citam o dever do *serviço militar obrigatório* (art. 143 da CF) e a *educação enquanto dever do Estado e da família* (art. 205);

■ **dever de exercício do direito de forma solidária e levando em consideração os interesses da sociedade:** como exemplo, os autores citam o *direito de propriedade* que deve ser exercido *conforme a sua função social* (art. 5.º, XXIII, da CF);

■ **deveres implícitos:** segundo Dimoulis, “existem tantos deveres implícitos quantos direitos explicitamente declarados”, consistindo referidos deveres em ação ou omissão. E conclui no sentido de que “o direito de uma pessoa pressupõe o *dever de todas as demais* (quando se aceita a tese do efeito horizontal direto) e, sobretudo, das autoridades do Estado”.[23](#)

■ 14.10. DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Dado o objetivo principal deste trabalho, qual seja, ferramenta para ajudar o candidato em concursos públicos, provas e mesmo na vida profissional, restringimo-nos a tecer breves comentários sobre os direitos individuais e coletivos, caso contrário abandonaríamos o nosso escopo.

■ 14.10.1. Direito à vida (art. 5.º, *caput*)

■ 14.10.1.1. Aspectos gerais

O direito à vida, previsto de forma genérica no art. 5.º, *caput*, abrange tanto o direito de não ser morto, de não ser privado da vida, portanto, o direito de

continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna.

Em decorrência do seu **primeiro desdobramento** (direito de não se ver privado da vida de modo artificial), encontramos a proibição da **pena de morte**, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX. Assim, mesmo por emenda constitucional é vedada a instituição da pena de morte no Brasil, sob pena de se ferir a cláusula pétrea do art. 60, § 4.º, IV.

Também, entendemos que o *poder constituinte originário* não poderia ampliar as hipóteses de pena de morte (nem mesmo uma nova Constituição) tendo em vista o **princípio da continuidade** e **proibição ao retrocesso**. Isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder.

Afastamo-nos, portanto, da ideia de *onipotência do poder constituinte*.

Canotilho observa que o poder constituinte “... é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta **espirituais, culturais, éticos e sociais** radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, nesta medida, considerados como ‘vontade do povo’”. Fala, ainda, na necessidade de observância dos **princípios de Justiça** (suprapositivos e supraleais) e, também, dos **princípios de direito internacional** (princípio da independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância de direitos humanos — neste último caso de vinculação jurídica, chegando a doutrina a propor uma juridicização e evolução do poder constituinte).²⁴

Toda essa argumentação reforça-se a partir da assinatura de diversos documentos internacionais, destacando-se:

■ **Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)**: “todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (art. III);

■ **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)**: “o direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida” (parte III, art. 6.º);²⁵

■ **Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos com vistas à Abolição da Pena de Morte (1989)**: “nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um Estado-Parte no

presente Protocolo será executado. Os Estados-Partes devem tomar as medidas adequadas para abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição” (art. 1.º, 1 e 2).[26](#)

Quanto ao **segundo desdobramento**, ou seja, o direito a uma **vida digna**, a Constituição garante as necessidades vitais básicas do ser humano e proíbe qualquer tratamento indigno, como a tortura, penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, cruéis etc.

Avançando, temos de definir quando começa a “vida” segundo a interpretação do STF, sem exprimir, nesse momento, juízo de valor pessoal, ético, filosófico ou religioso, até porque, nesse último caso, o Brasil é um país laico (art. 19, I, da CF/88).

■ 14.10.1.2. Células-tronco embrionárias

O STF definiu o **conceito de vida** no julgamento da **ADI 3.510** que tratava da análise do art. 5.º da Lei n. 11.105/2005 (*Lei de Biossegurança*).

Em 20.04.2007 foi realizada a primeira **audiência pública** à luz da Lei n. 9.868/99, objetivando **pluralizar o debate** e dar **maior legitimidade** à decisão.[27](#)

Os argumentos do PGR eram no sentido de que a *Lei de Biossegurança* violava o **direito à vida** e a **dignidade da pessoa humana**, sendo que a vida humana começa a partir da *fecundação*.

Desde o ajuizamento da ADI (03.05.2005) até a solução final (29.05.2008) foram mais de 3 anos e o STF concluiu, por votação bastante apertada, 6 x 5, que as pesquisas com célula-tronco embrionária, nos termos da lei, não violam o direito à vida.

Os Ministros vencidos propunham a observância de *outras condicionantes* além daquelas do art. 5.º da Lei, ingerência que chegou a ser considerada indevida, sob pena de se violar o princípio da separação de “poderes”.

O Ministro Relator, Carlos Ayres Britto, entendeu tratar-se de um “bem concatenado bloco normativo” fixado pela lei, destacando-se o procedimento: **a)**

para fins de pesquisa e terapia; **b)** somente em relação às células-tronco embrionárias; **c)** apenas aquelas fertilizadas *in vitro*; **d)** embriões inviáveis ou congelados há pelo menos 3 anos; **e)** consentimento dos genitores; **f)** controle por comitê de ética em pesquisa; **g)** proibição da comercialização.

Além disso, segundo interpretação do Relator, o texto, ao tratar de “dignidade da pessoa humana” (art. 1.º, III), “direitos da pessoa humana” (art. 34, VII, “b”), “livre-exercício dos direitos... individuais” (art. 85, III), “direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4.º, IV), estaria se referindo a direitos do indivíduo-pessoa, já nascido (cf. *Inf. 508/STF*).

Nesse ponto, deixamos, com o máximo respeito, a nossa **crítica**, pois não nos parece tenha o texto se omitido de destinar esses direitos e garantias ao nascituro, que, segundo o Relator, de fato, tem proteção legal, por exemplo, no art. 2.º do CC; no art. 9.º, § 7.º, da Lei de Transplantes (Lei n. 9.434/97); nos arts. 124-126 do CP (aborto).

Segundo o Relator, o **zigoto** seria o embrião em estágio inicial, pois ainda destituído de cérebro. A vida humana começaria com o surgimento do cérebro, que, por sua vez, só apareceria depois de introduzido o embrião no útero da mulher. Assim, antes da introdução no útero não se teria cérebro e, portanto, sem cérebro, não haveria vida.

A constatação de que a vida começa com a existência do cérebro (segundo o STF e sem apresentar qualquer análise axiológica ou filosófica) estaria estabelecida, também, no art. 3.º da Lei de Transplantes, que prevê a possibilidade de transplante depois da morte desde que se constate a **morte encefálica**. Logo, para a lei, o fim da vida dar-se-ia com a morte cerebral e, novamente, sem cérebro, não haveria vida e, portanto, nessa linha, o conceito de vida estaria ligado (segundo o STF) ao surgimento do cérebro.

Outro argumento utilizado foi a ideia de **dignidade da pessoa humana** e **paternidade responsável**, lembrando o art. 226, § 7.º.

De fato, o Estado não pode, constitucionalmente, restringir a quantidade de filhos por casal. A Constituição, contudo, determina o dever de orientação em relação ao **planejamento familiar**.

Dessa forma, afirmou o Ministro Relator, se não se define o número de filhos, feita a fertilização *in vitro* o casal pode optar pela quantidade de embriões a serem introduzidos no útero. Se eventualmente não quiserem introduzir todos, os embriões poderão ser congelados.

E se o casal não tiver como congelar (até porque isso gera custo)? Respondeu outro Ministro, indagando: serão os embriões jogados como lixo hospitalar? Então, que se admita a pesquisa, dentro dos critérios éticos fixados na lei e consagrando a ideia de uma **sociedade fraterna** (preâmbulo e art. 3.º, I, além da ideia de direitos de *3.a dimensão*), objetivando a cura das pessoas com doenças degenerativas (e nos parece que, nesse ponto, bastante acertada a decisão).

Outros argumentos poderiam ser mencionados, como o **direito à saúde** (arts. 196-200) e o **incentivo ao desenvolvimento e à pesquisa científica** (arts. 218-219).

■ 14.10.1.3. Interrupção de gravidez de feto anencefálico

Desconsiderando os aspectos moral, ético ou religioso, tecnicamente, em relação à **interrupção da gravidez de feto anencefálico**,²⁸ desde que se comprove, por laudos médicos, com 100% de certeza, que o feto não tem cérebro e não há perspectiva de sobrevivência (situação não imaginada na década de 1940 — quando o Código Penal foi elaborado — e, atualmente, totalmente viável em razão da **evolução tecnológica**), nessa linha de desenvolvimento, o STF, para seguir a lógica do julgamento anterior (célula-tronco), teria de autorizar a possibilidade de antecipação terapêutica do parto.

Esse tema, como todos sabem, foi enfrentado pelo STF no julgamento da **ADPF 54**, ajuizada pela *Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde* — *CNTS*.

Conforme anotou o Min. Marco Aurélio em seu voto, “não se coaduna com o **princípio da proporcionalidade** proteger apenas um dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, **não tem sequer expectativa de vida extrauterina**, aniquilando, em contrapartida, os direitos da mulher,

impingindo-lhe sacrifício desarrazoado. A imposição estatal da manutenção de gravidez cujo resultado final será irremediavelmente a morte do feto vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mais precisamente à **dignidade da pessoa humana**, à **liberdade**, à **autodeterminação**, à **saúde**, ao **direito de privacidade**, ao **reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres**. O ato de obrigar a mulher a manter a gestação, colocando-a em uma espécie de **cárcere privado em seu próprio corpo**, desprovida do mínimo essencial de **autodeterminação** e **liberdade**, assemelha-se à **tortura** ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou dela exigido”.

Dessa forma, em **12.04.2012**, por maioria de votos, o Plenário do STF, enaltecendo o direito à dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à autonomia, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral e à saúde (arts. 1.º, III; 5.º, *caput*, e incisos II, III e X; e 6.º, *caput*, da CF/88), julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade de interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos arts. 124, 126 e 128, I e II, todos do Código Penal (cf. *Inf. 661/STF*).

■ **14.10.1.4. Eutanásia**

Dentro da ideia de vida digna, a **eutanásia** ganha destaque, pois o direito à vida quer significar, também, o direito de viver com dignidade (tema, inclusive, que está sendo discutido no *Projeto de Novo Código Penal* — pendente).

A *eutanásia passiva* vem adquirindo vários defensores (o desligamento de aparelhos que apenas prolongam a vida de doentes em estágio terminal, sem diagnóstico de recuperação), assim como o suicídio assistido. Alguns falam que a eutanásia ativa (o Estado — médico — provocando a morte) seria homicídio.

O tema está lançado e precisa ser mais bem desenvolvido pela sociedade, inclusive em audiências públicas. [29](#)

A ideia de **bom senso**, **prudência** e **razoabilidade** deve ser considerada.

A vida deve ser vivida com dignidade. Definido o seu início (tecnicamente, pelo STF), não se pode deixar de considerar o sentimento de cada um. A decisão individual terá de ser respeitada. A fé e a esperança não podem ser menosprezadas e, portanto, a frieza da definição não conseguirá explicar e convencer os milagres da vida. Há situações que não se explicam matematicamente e, dessa forma, a decisão pessoal (dentro da ideia de ponderação) deverá ser respeitada. O radicalismo não levará a lugar algum. A Constituição garante, ao menos, apesar de ser o Estado laico, o amparo ao sentimento de esperança e fé que, muitas vezes, dá sentido a algumas situações incompreensíveis da vida.

■ 14.10.2. Princípio da igualdade (art. 5.º, *caput*, I)

■ 14.10.2.1. Aspectos gerais

O art. 5.º, *caput*, consagra serem todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal (consagrada no *liberalismo clássico*), mas, principalmente, a **igualdade material**.

Isso porque, no *Estado social* ativo, efetivador dos direitos humanos, imagina-se uma igualdade mais real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada em face da lei.

Essa busca por uma **igualdade substancial**, muitas vezes idealista, reconheça-se, eterniza-se na sempre lembrada, com emoção, *Oração aos Moços*, de Rui Barbosa, inspirada na lição secular de Aristóteles, devendo-se *tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades*.

Em diversas hipóteses a própria Constituição se encarrega de aprofundar a regra da **isonomia material**: **a)** art. 3.º, I, III e IV; **b)** art. 4.º, VIII; **c)** art. 5.º, I,

XXXVII, XLI e XLII; **d**) art. 7.º, XX, XXX,[30](#) XXXI, XXXII e XXXIV; **e**) art. 12, §§ 2.º e 3.º; **f**) art. 14, *caput*; **g**) art. 19, III; **h**) art. 23, II e X; **i**) art. 24, XIV; **j**) art. 37, I e VIII; **k**) art. 43, *caput*; **l**) art. 146, III, “d” (EC n. 42/2003 — Reforma Tributária); **m**) art. 150, II; **n**) art. 183, § 1.º, e art. 189, parágrafo único; **o**) art. 203, IV e V; **p**) art. 206, I; **q**) art. 208, III; **r**) art. 226, § 5.º; **s**) art. 231, § 2.º etc.

Em outras, é o próprio constituinte quem estabelece as desigualdades, por exemplo, em relação à igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, nos termos da Constituição, destacando-se as seguintes diferenciações: **a**) art. 5.º, L (*condições às presidiárias para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação*); **b**) art. 7.º, XVIII e XIX (*licença-maternidade e licença-paternidade*); **c**) art. 143, §§ 1.º e 2.º (*serviço militar obrigatório*); **d**) arts. 201, § 7.º, I e II; 201, § 8.º; art. 9.º da EC n. 20/98; art. 40 da CF/88; art. 8.º da EC n. 20/98; arts. 2.º e 6.º da EC n. 41/2003 — Reforma da Previdência — dentre outros (*regras sobre aposentadoria*).

Além dessas e de outras hipóteses expressamente previstas na CF/88, a grande dificuldade consiste em saber até que ponto a desigualdade não gera inconstitucionalidade.

Celso Antônio Bandeira de Mello parece ter encontrado parâmetros sólidos e coerentes em sua clássica monografia sobre o tema do **princípio da igualdade**, na qual fala em três questões a serem observadas, a fim de se verificar o respeito ou desrespeito ao aludido princípio. O desrespeito a qualquer delas leva à inexorável ofensa à isonomia. Resta, então, enumerá-las: “a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; b) a segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de *discrímen* e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados”.[31](#)

■ 14.10.2.2. “Separate but equal” e “Treatment as an equal”

Destacamos, antes das ações afirmativas, a teoria dos *Separate but equal*, que vigorou durante muito tempo nos Estados Unidos e consistia na separação (*separate*) de brancos e negros, porém, assegurando uma prestação de serviços idênticos (*equal*). Assim, por exemplo, existiam escolas para negros e escolas para brancos, mas, embora separados, a qualidade de ensino deveria ser igual. O mesmo acontecia em relação ao transporte, ou seja, vagões para brancos e vagões para negros.

Essa teoria, que veio a ser superada pela do *Treatment as an equal*, precisou, em vários casos, das ações afirmativas para afastar o sentimento de discriminação que vigorou por muitos anos. Atualmente, as próprias ações afirmativas estão sendo revistas, no sentido de que a igualdade já está assegurada de modo substancial, não havendo mais necessidade de interferência do Estado.

■ 14.10.2.3. **Ações afirmativas — três importantes precedentes da Suprema Corte (Cotas Raciais, PROUNI e Lei Maria da Penha) e a Lei n. 12.990/2015**

Esses critérios podem servir de parâmetros para a aplicação das denominadas **discriminações positivas**, ou *affirmative actions*,³² tendo em vista que, segundo David Araujo e Nunes Júnior, “... o constituinte tratou de proteger certos grupos que, a seu entender, mereceriam tratamento diverso. Enfocando-os a partir de uma realidade histórica de marginalização social ou de hipossuficiência decorrente de outros fatores, cuidou de estabelecer **medidas de compensação**, buscando concretizar, ao menos em parte, uma igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as mesmas espécies de restrições”.³³

Passamos a destacar importantes precedentes estabelecidos pelo STF.

Em primeiro lugar, lembramos, em **26.04.2012**, o julgamento das **cotas raciais**, notadamente a discussão travada na **ADPF 186**, que considerou **constitucional** a política de cotas étnico-raciais para seleção de estudantes da Universidade de Brasília (UnB) (para um outro precedente, cf. julgamento do

RE 597.285 que discute o sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Conforme ponderou o Min. Lewandowski, relator do caso, “as experiências submetidas ao crivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais, historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. No caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros e de ‘um pequeno número’ delas para ‘índios de todos os Estados brasileiros’, pelo prazo de 10 anos, constitui providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desideratos. Dito de outro modo, a política de ação afirmativa adotada pela UnB não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se, também sob esse ângulo, compatível com os valores e princípios da Constituição” (fls. 46-47 de seu voto).

Ainda, o STF declarou o reconhecimento da proclamação na Constituição da **igualdade material**, sendo que, para assegurá-la, “o Estado poderia lançar mão de políticas de cunho universalista — a abranger número indeterminado de indivíduos — mediante **ações de natureza estrutural**; ou de **ações afirmativas** — a atingir **grupos sociais determinados** — por meio da atribuição de certas vantagens, por **tempo limitado**, para permitir a **suplantação de desigualdades ocasionadas por situações históricas particulares**. Certificou-se que a adoção de políticas que levariam ao afastamento de perspectiva meramente formal do princípio da isonomia integraria o cerne do conceito de democracia. Anotou-se a superação de concepção estratificada da igualdade, outrora definida apenas como direito, sem que se cogitasse convertê-lo em possibilidade” (*Inf. 663/STF*).

A partir desse julgamento, devemos destacar, em momento seguinte, a aprovação da **Lei n. 12.990/2014** que reserva aos negros **20%** das vagas oferecidas nos **concursos públicos** para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da **administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União**.

Na medida em que a legislação é explícita ao estabelecer a reserva de vagas

apenas no âmbito do Poder Executivo Federal, muitos vêm discutindo a extensão dessas regras para o âmbito dos demais entes federativos e, ainda, para os concursos realizados no Judiciário e no Legislativo.

Procurando minimizar essa polêmica, em **18.03.2015**, levando em consideração a decisão firmada na *ADPF 186*, bem como a *Lei n. 12.990/2014* e o **Estatuto da Igualdade Racial** (Lei n. 12.288/2010), o presidente do STF e do CNJ, Min. Lewandowski, assinou atos normativos instituindo a reserva de vagas dentro do limite fixado na citada Lei n. 12.990/2014, qual seja, **10 anos** a partir de sua publicação, para os concursos de provimento de cargos efetivos nos âmbitos do STF (**Res. n. 548/2015**) e do CNJ (**IN n. 63/2015**).

Durante a solenidade, o Min. Lewandowski afirmou que em breve o CNJ vai analisar a implantação das regras para os concursos públicos de todo o Judiciário brasileiro. Conforme afirmou, “O que o Supremo Tribunal Federal faz hoje é um primeiro passo, mas **que em breve deverá ser estendido, por meio de decisão do Conselho Nacional de Justiça, para toda a magistratura**”, afirmou durante a cerimônia. O presidente do STF destacou que segundo dados do último censo realizado pelo IBGE, em toda a magistratura brasileira figuram apenas 1,4% de negros” (*Notícias STF de 18.03.2015*).

Em segundo lugar, dentro dessa ideia de **política de cotas** e diante de toda a problemática gerada por outras iniciativas, o Governo Federal, através da **MP n. 213**, de 10.09.2004, instituiu o **PROUNI — Programa Universidade para Todos**, que foi regulamentado pelo Decreto n. 5.493/2005. A Medida Provisória n. 213 foi objeto das ADIs 3.314 e 3.379, apensadas à **ADI 3.330**, e, posteriormente, convertida na **Lei n. 11.096/2005**.

O art. 1.º da Lei, ao instituir o PROUNI, dispõe tratar-se de programa destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% ou de 25% para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.

O art. 2.º destina a bolsa para: **a)** estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de

bolsista integral; **b)** estudante portador de deficiência, nos termos da lei; **c)** professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§ 1.º e 2.º do art. 1.º desta Lei.

Por maioria de votos, o STF, em **03.05.2012**, julgou **constitucional** o **PROUNI**, como importante **fator de inserção social** e cumprimento do art. 205 da CF/88, que estatui ser a educação direito de todos e **dever** do Estado e da família.

Ainda, o programa encontra-se em sintonia com diversos dispositivos da Constituição que estabelecem a **redução de desigualdades sociais**.

Não se poderia sustentar violação ao *princípio da autonomia universitária*, previsto no art. 207 da CF/88, na medida em que a adesão ao programa é **facultativa** (art. 5.º, *caput*, da Lei n. 11.096/2005).

Também, não se acatou a argumentação de violação ao princípio da livre-iniciativa (art. 170, parágrafo único), tendo em vista “a ociosidade de vagas nas instituições de ensino superior, a favorecer a manutenção de suas atividades, frente aos benefícios tributários de que passariam a usufruir” (*Inf. 664/STF*).

No mais, a isonomia substancial mostra-se fortalecida, uma vez que o programa permite o cumprimento da regra contida no art. 206, I: **princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola**.

Finalmente, destacamos decisão do STF pela qual se adotaram interpretações mais protetivas às mulheres em relação a dispositivos da Lei n. 11.340/2006 (**Lei Maria da Penha**), em nítida **ação afirmativa com o objetivo de intimidar a prática de violência doméstica**.

O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em **09.02.2012**, julgou procedente a **ADC 19**, para declarar a constitucionalidade dos arts. 1.º, 33 e 41 da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), tendo por fundamento o **princípio da igualdade**, bem como o **combate ao desprezo às famílias**, sendo considerada a **mulher** a sua **célula básica**.

Na mesma assentada, por maioria e nos termos do voto do Relator, o STF

julgou procedente a **ADI 4.424**, para, dando interpretação conforme os arts. 12, I, e 16, ambos da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), declarar a **natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico** (cf. *item 19.9.5*).

■ 14.10.2.4. Ações afirmativas — indicação de Ministros para o STF

Temos, ainda, 2 exemplos de **ações afirmativas**, quais sejam, a indicação de uma **mulher** e de um **negro** para o STF, isso depois de mais de 200 anos e 289 Ministros nomeados (quantidade até o fechamento desta edição), considerando que o STF tem a sua origem histórica no início do século XIX (*Casa da Suplicação do Brasil* — ainda na fase colonial, em 10.05.1808, e *Supremo Tribunal de Justiça*, em 09.01.1829 — *vide item 11.8.1*).

Como se sabe, *Ellen Gracie Northfleet* foi a **primeira mulher** a integrar o STF, tendo tomado posse em 14.12.2000. Conforme asseverou o Ministro Celso de Mello, “o ato de escolha da Ministra Ellen Gracie para o Supremo Tribunal Federal — **além** de expressar a celebração de um novo tempo — teve o significado de verdadeiro rito de passagem, **pois inaugurou**, de modo positivo, na história judiciária do Brasil, uma clara e irreversível transição para um modelo social **que repudia a discriminação de gênero**, ao mesmo tempo **em que consagra a prática afirmativa e republicana da igualdade**”.³⁴

Em relação à indicação de um **Ministro negro**, conforme noticiado pelo STF, “o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende indicar um ministro negro para uma das próximas vagas que abrirão para o Supremo Tribunal Federal. A informação foi dada na manhã de hoje (7/4/03) pela secretária Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, com quem esteve em audiência. A secretária disse que conversou com Marco Aurélio sobre **ações afirmativas**, e declarou, após o encontro: ‘Estamos vivendo um período bastante positivo em que este governo está, de fato, sendo

propositivo e indicando pessoas que não tiveram acesso ao poder, considerando que o nosso país é bastante discriminatório e racista’. A secretária afirmou também que o debate desse tema ‘deve ser aprofundado’”. [35](#)

Essa pretensão do Presidente Lula, como todos sabem, foi confirmada pela indicação do *Ministro Joaquim Barbosa*, que, juntamente com Cezar Peluso e Carlos Britto, tomou posse no STF em 25.06.2003.

■ 14.10.2.5. Princípio da congeneridade

Outro assunto causou muita polêmica, a qual foi vivenciada pelos amigos do Distrito Federal.

O art. 49 da Lei n. 9.394/96 (*que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*) prescreve que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e **mediante processo seletivo**.

O parágrafo único do aludido dispositivo, por seu turno, prescreve que as transferências *ex officio* dar-se-ão na forma da lei.

A Lei n. 9.536/97 regulamenta o assunto. O seu art. 1.º prevê que a transferência *ex officio* será efetivada, *entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino*, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida por motivo de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o Município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta, não se aplicando essa regra quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.

Em virtude dessa regra e de *Parecer AGU/RA 02/2004*, o Conselho Universitário da Universidade de Brasília (UnB) decidiu **suspender o vestibular para o curso de Direito** tamanha a quantidade de pedidos de transferência, sobretudo de filhos de militares. A situação se agrava haja vista ser a Capital

Federal, sem dúvida, um grande centro de concentração do oficialato militar.

Diante de toda essa polêmica, foi proposta a [ADI 3.324](#), pelo PGR, questionando a aludida sistemática, especialmente a transferência de militares e dependentes estudantes em universidades particulares para públicas.

“Em decisão unânime, o Plenário do STF julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3324)... O Plenário acompanhou o voto do relator, Ministro Marco Aurélio, que decidiu dar ao artigo 1.º da Lei 9.536/1997 *interpretação conforme a Constituição Federal*, de modo a autorizar a transferência obrigatória desde que a instituição de destino seja *congênere* à de origem, ou seja, de pública para pública ou de privada para privada.”

“O Ministro Gilmar Mendes, que também acompanhou o voto do relator, disse que ‘o critério da congeneridade é estritamente proporcional ao caso porque garante o ingresso *ex officio*, como garante a integridade da autonomia universitária, além de preservar minimamente o interesse daqueles que não são servidores públicos civis ou militares ou seus dependentes, ou seja, a grande maioria da população brasileira’” (*Notícias STF*, 16.12.2004 — 18h34).

Em relação ao *servidor público federal civil*, cabe destacar, no mesmo sentido do julgamento da ADI 3.324, o art. 99 da Lei n. 8.112/90, que garante a “matrícula em instituição de ensino congênere”. [36](#)

■ 14.10.2.6. *Foro da residência da mulher no CPC/73. Nova regra trazida pelo CPC/2015 (foro de domicílio do guardião de filho incapaz)*

O STF, em discutível decisão, analisando a regra contida no art. 100, I, do CPC/73, que determina ser competente o foro da residência da mulher para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de casamento, entendeu não haver afronta ao princípio da igualdade entre homens e mulheres (art. 5.º, I, CF/88), nem mesmo à isonomia entre os cônjuges (art. 226, § 5.º, da CF/88), declarando, então, a sua recepção pela Constituição ([RE 227.114](#), Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 22.11.2011, 2.ª T.,

DJE de 16.02.2012).

O **CPC/2015**, modificando a regra do CPC/73, não mais prevê o foro privilegiado da residência da mulher, pois estabelece como premissa a vulnerabilidade do guardião e do filho incapaz (conjuntamente considerados).

Pela nova regra contida no **art. 53, I**, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o **foro de domicílio do guardião de filho incapaz**. Caso não haja filho incapaz, o do último domicílio do casal. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, o do réu.

■ **14.10.2.7. Art. 384 da CLT: intervalo de 15 minutos para as mulheres antes de hora extra**

Ainda para se aprofundar o tema da isonomia entre homens e mulheres (art. 5.º, I), destacamos a discussão sobre a recepção ou não do **art. 384 da CLT** que, tratando da proteção do trabalho da **mulher**, estabeleceu, para a hipótese de prorrogação do horário normal, a obrigatoriedade de **descanso de 15 minutos, no mínimo**, antes do início do período extraordinário.

Resta saber se essa distinção encontra fundamento na Constituição, já que destinada apenas para a **mulher**. Analisando os artigos da Carta Magna, não há qualquer regra expressa sobre a hipótese tratada na CLT. Encontramos apenas a previsão genérica do art. 7.º, XX, que assegura a proteção do mercado de trabalho da **mulher**, mediante incentivos **específicos**, nos termos da **lei**.

Essa garantia **exclusiva da trabalhadora mulher**, muito embora polêmica diante do princípio da isonomia, desde 17.11.2008, já vinha sendo reconhecida pelo **TST** desde o julgamento de questão de ordem resolvida pelo Pleno em recurso de revista (**TST-IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5**).

O **STF**, por maioria apertada (5 x 4), referendou esse entendimento, **reconhecendo a recepção do art. 384 da CLT** no julgamento do **RE 658.312** (j. 27.11.2014, pendente de publicação quando do fechamento desta edição).

Para o Min. Dias Toffoli, Relator, dois foram os argumentos a ensejar o

tratamento desigual entre os gêneros: **a)** existência de componente orgânico e biológico a justificar a desigualação, inclusive diante de menor resistência física da mulher; **b)** existência de componente social justificado pela dita dupla jornada da mulher, no lar e no ambiente de trabalho.

Realmente, um tema bastante delicado e que ainda poderá ser repensado no futuro diante da nova posição que, felizmente, a mulher vem adquirindo na sociedade. Nesse caso, a alteração poderá ocorrer tanto por mudança de entendimento da Corte (lembramos que o citado recurso extraordinário foi decidido por 5 x 4), como em razão de modificação do citado artigo da CLT por lei a ser editada pelo Congresso Nacional. Nessa hipótese de alteração normativa, podemos pensar tanto a revogação do art. 384 da CLT, como a ampliação do direito consagrado também para os homens trabalhadores.

■ 14.10.3. Princípio da legalidade (art. 5.º, II)

O princípio da legalidade surgiu com o Estado de Direito, opondo-se a toda e qualquer forma de poder autoritário, antidemocrático.

Esse princípio já estava previsto no art. 4.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No direito brasileiro vem contemplado nos arts. 5.º, II; 37; e 84, IV, da CF/88.

O inciso II do art. 5.º estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Mencionado princípio deve ser lido de forma diferente para o **particular** e para a **administração**. Vejamos:

No âmbito das **relações particulares**, pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da **autonomia da vontade**, lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com o da **dignidade da pessoa humana** e, assim, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, conforme estudado.

Já no que tange à **administração**, esta só poderá fazer o que a lei permitir. Deve andar nos “trilhos da lei”, corroborando a máxima do direito inglês: *rule of law, not of men*. Trata-se do **princípio da legalidade estrita**, que, por seu

turno, **não é absoluto!** Existem algumas restrições, como as medidas provisórias, o estado de defesa e o estado de sítio, já analisados por nós neste trabalho.

■ 14.10.4. Proibição da tortura (art. 5.º, III)

Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, sendo que a lei considerará crime inafiançável a prática da tortura (**art. 5.º, XLIII, CF/88**). A **Lei n. 9.455/97** integrou a referida norma constitucional, definindo os crimes de tortura. Por sua vez, a **Lei n. 12.847/2013**, além de instituir o *Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura*, criou o *Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura* e o *Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura*.

Conforme jurisprudência do STF, “o uso legítimo de **algemas** não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. O emprego dessa medida tem como balizamento jurídico necessário os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.08.2006, *DJ* de 02.02.2007).

Nesse sentido, devemos destacar a **SV 11/2008**, com a seguinte redação: “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Outro tema importante diz respeito à análise da recepção da chamada **Lei da Anistia** (Lei n. 6.683/79) pelo novo ordenamento, levado ao STF pela OAB na **ADPF 153**, que pretendia fosse anulado o perdão dado aos policiais e militares

acusados de praticar atos de tortura, durante o regime militar, e que encontrava respaldo no art. 1.º da referida lei, com a seguinte redação:

“É **concedida anistia** a todos quantos, no período compreendido entre 02.09.61 e 15.08.79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos **servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares** e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares”.

O STF, por **7 x 2**, entendeu como não admitida a revisão jurisdicional da *Lei da Anistia*, sustentando ter sido “... uma **decisão política** assumida naquele momento — o momento da transição conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é uma **lei-medida**, não uma regra para o futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de ser **interpretada a partir da realidade no momento em que foi conquistada**. A Lei n. 6.683/1979 precede a *Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes* — adotada pela Assembleia Geral em 10.12.1984, vigorando desde 26.06.87 — e a Lei n. 9.455, de 07.04.1997, que define o crime de tortura; e o preceito veiculado pelo art. 5.º, XLIII, da Constituição — que declara insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, entre outros crimes — não alcança, por impossibilidade lógica, anistias anteriormente à sua vigência consumadas. **A Constituição não afeta leis-medida que a tenham precedido**” (ADPF 153).

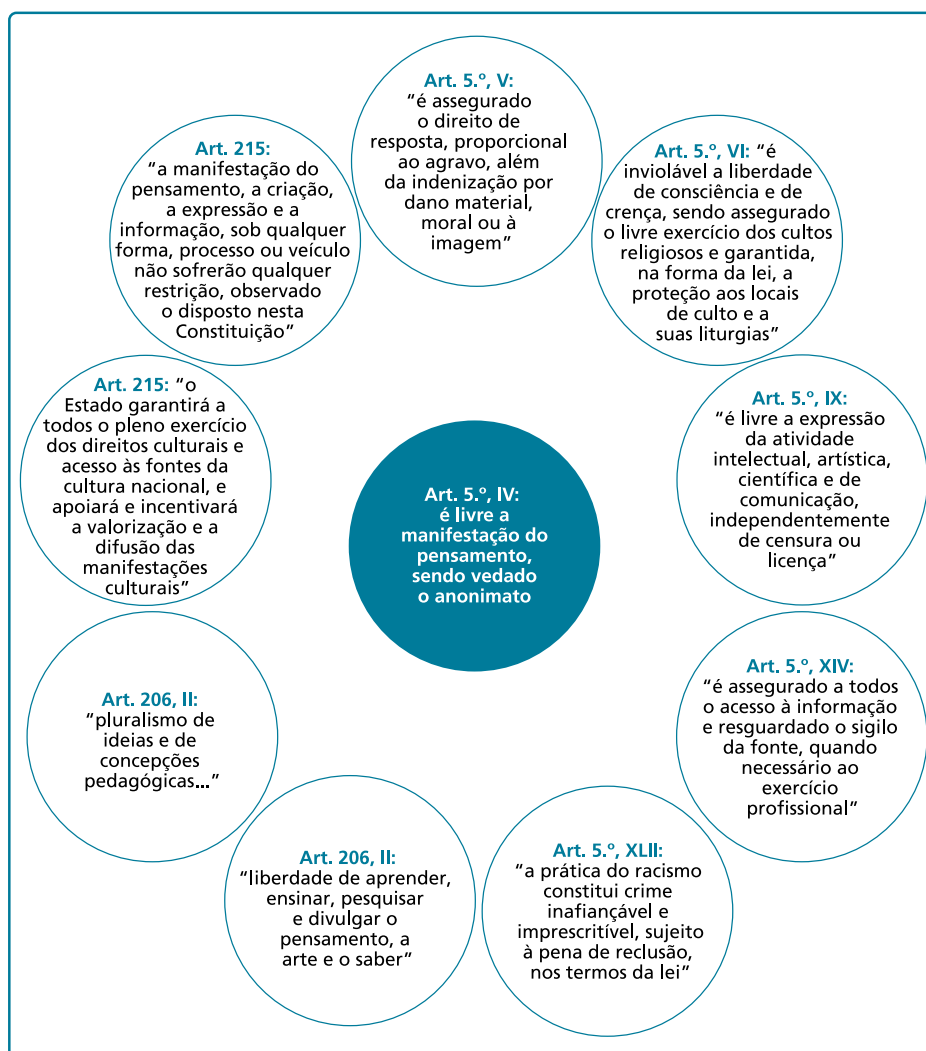
■ 14.10.5. Liberdade da manifestação de pensamento (art. 5.º, IV e V)

A Constituição assegurou a liberdade de manifestação do pensamento, vedando o anonimato. Caso durante a manifestação do pensamento se cause dano material, moral ou à imagem, assegura-se o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização.

Tem razão Ingo Sarlet ao afirmar que a regra contida no referido **art. 5.º, IV**,

CF/88, estabelece uma espécie de “**cláusula geral**” que, em conjunto com outros dispositivos, asseguram a **liberdade de expressão** nas suas diversas manifestações:

- liberdade de manifestação do pensamento (incluindo a liberdade de opinião);
- liberdade de expressão artística;
- liberdade de ensino e pesquisa;
- liberdade de comunicação e de informação (liberdade de “imprensa”);
- liberdade de expressão religiosa. [37](#)



Isso posto, nessa parte, passamos a tecer alguns comentários pontuais, destacando-se precedentes do STF, lembrando que os temas da divisão apontada

acima serão estudados em tópicos próprios. Vejamos.

■ **14.10.5.1. Liberdade de expressão e a problemática do “hate speech”.
“Posição de preferência” da liberdade de expressão. Interessante exemplo
no âmbito da rede mundial de computadores (“marco civil da internet”
— Lei n. 12.965/2014)**

A problemática do *hate speech* (discurso do ódio) evidencia-se em precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos ao fazer interpretações da primeira emenda à Constituição (*first amendment*), que assegurou a **liberdade de expressão** nos seguintes termos: “Congress shall make no law (...) **abridging** the freedom of speech, or of the press” (“o Congresso não pode elaborar nenhuma lei **limitando** — **cerceando** a liberdade de expressão ou de imprensa”).

Conforme anotou Daniel Sarmiento em trabalho de fôlego (produzido durante a sua estadia como *visiting scholar* na Universidade de Yale — EUA, durante o primeiro semestre de 2006), a análise do *hate speech* está relacionada à **liberdade de expressão** e às “manifestações de **ódio, desprezo** ou **intolerância** contra determinados **grupos**, motivadas por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual, dentre outros fatores...”.[38](#)

Em suas conclusões, o Brasil, inclusive o nosso STF, **não** adotou o entendimento de que a garantia da liberdade de expressão abrangeria o *hate speech*. Ou seja, muito embora a “**posição de preferência**”[39](#) que o direito fundamental da **liberdade de expressão** adquire no Brasil (com o seu especial significado para um país que vivenciou atrocidades a direitos fundamentais durante a ditadura), assim como em outros países, a **liberdade de expressão não é absoluta**, encontrando restrições “voltadas ao combate do preconceito e da intolerância contra minorias estigmatizadas”.[40](#)

Mas o autor alerta: “... num país como o nosso, em que a cultura da liberdade de expressão ainda não deitou raízes, há que se ter cautela e equilíbrio no

percurso deste caminho, para que os nobres objetivos de promoção da tolerância e de defesa dos direitos humanos dos excluídos não resvalam para a perigosa tirania do politicamente correto”.[41](#)

Para tanto, o modelo de solução parece ser, conforme sugere e com o qual concordamos, o da **ponderação**, pautada pelo **princípio da proporcionalidade** e a ser analisado no caso concreto, como se observou, para se ter um exemplo, no julgamento da ADPF 130 (não recepção da lei de imprensa).[42](#)

Ainda, outra orientação importante sobre o tema é a de que eventual **restrição prévia à liberdade de expressão** somente seria admitida por meio de **decisão judicial** e “em hipóteses **absolutamente excepcionais**... em favor da tutela de direitos ou outros bens jurídicos contrapostos”.[43](#)

No tocante à limitação legislativa **prévia à liberdade de expressão**, muito embora o voto condutor proferido pelo Min. Ayres Britto no julgamento da ADPF 130, negando-a, **em outro julgado**, que entendeu como inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão, estabeleceu o Min. Gilmar Mendes, no item 6 da ementa do acórdão: “as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidas pela **lei** em **hipóteses excepcionais**, sempre em razão da **proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral**. Precedente do STF: ADPF n. 130, Rel. Min. Carlos Britto” (RE 511.961, j. 17.06.2009).

Essa limitação, conforme sustenta Sarmento, deve se dar “de forma geral e abstrata, desde que respeitados os ‘limites dos limites’ dos direitos fundamentais, notadamente o princípio da proporcionalidade”.[44](#)

Nessa mesma linha sugerida por Sarmento, Ingo Sarlet estabelece: “doutrina e jurisprudência, notadamente o STF, embora adotem a **tese da posição preferencial da liberdade de expressão**, admitem **não se tratar de direito absolutamente infenso a limites e restrições**, desde que eventual restrição tenha **caráter excepcional**, seja promovida por **lei** e/ou **decisão judicial** (visto que vedada toda e qualquer censura administrativa) e tenha por fundamento a

salvaguarda da dignidade da pessoa humana (que aqui opera simultaneamente como limite e limite aos limites de direitos fundamentais) e de direitos e bens jurídicos-constitucionais individuais e coletivos fundamentais, observados os critérios da proporcionalidade e da preservação do núcleo essencial dos direitos em conflito”.⁴⁵

Essa perspectiva em relação à *liberdade de expressão*, para se ter um exemplo, verifica-se no art. 19⁴⁶ da Lei n. 12.965/2014 (conhecida como “marco civil da *internet*”) que assegurou a liberdade de expressão na rede mundial de computadores, salvo *ordem judicial específica*, com exceção apenas aos conteúdos de nudez ou de atos sexuais de caráter privado (art. 21).⁴⁷

■ **14.10.5.2. Ainda a problemática do “hate speech” (discursos de incitação ao ódio). Liberdade de expressão e a prática do crime de racismo: precedente histórico na jurisprudência do STF — HC 82.424. A liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto**

Conforme vimos, muito embora a “posição de preferência” que pode ser reconhecida na doutrina e jurisprudência em relação à *liberdade de expressão*, esse direito fundamental não é absoluto.

Em caso concreto, discutia-se a prática ou não de crime de racismo cometido por escritor e editor de *livros* por suposta discriminação contra os judeus (art. 5.º, XLII) ao pregar ideias antissemitas, preconceituosas e discriminatórias. Absolvido em primeira instância, a 3.ª Câmara Criminal do TJRS, por unanimidade, reformou a sentença e o condenou. Impetrado HC no STJ, a ordem foi denegada. Houve nova impetração de *habeas corpus* no STF, ora em análise (**HC 82.424**).

O STF, por **8 x 3**, em julgamento finalizado em 17.09.2003, manteve a condenação imposta pelo TJRS por crime de racismo, flexibilizando a amplitude da liberdade de expressão. Em razão da importância do tema (o Min. Marco Aurélio, que ficou vencido e defendeu a tese da liberdade de expressão, definiu o julgamento como *um dos mais importantes da Corte* desde a sua chegada há 13 anos), pedimos vênias para transcrever a ementa:

“1. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros ‘fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias’ contra a comunidade judaica (Lei n. 7.716/89, art. 20, na redação dada pela Lei n. 8.081/90) constitui **crime de racismo** sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, art. 5.º, XLII). (...). 10. A edição e publicação de obras escritas veiculando ideias antissemitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos como o **holocausto**, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação ao *discrimen* com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam. (...). 15. (...). Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os **atos repulsivos** do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem” (HC 82.424, Rel. p/ o ac. Min. Presidente Maurício Corrêa, j. em 17.09.2003, Plenário, DJ de 19.03.2004).

A maioria dos Ministros, apesar de pequenas distinções metodológicas, justificou os seus votos com base na ideia de **ponderação (sopesamento)** entre a **liberdade de expressão e a liberdade de imprensa** de um lado e a **dignidade da pessoa humana e o direito à honra** de outro.

Sem discutir a problemática sobre a possibilidade de sopesamento da dignidade da pessoa humana, *Virgílio Afonso da Silva* apresenta críticas à metodologia da decisão. Para o autor, como já existe a previsão de **mediação normativa** — no caso, a criminalização da prática de racismo prevista na lei —, **não haveria sentido falar-se em colisão de direitos fundamentais**. A escolha já foi feita pelo legislador ao prestigiar a dignidade da pessoa humana contra a liberdade de expressão. Portanto, o autor sugere que o modelo da decisão não foi o mais adequado. No caso, eventual discordância sobre o acerto ou não do legislador ao fazer a escolha deveria ser analisada em **incidente de inconstitucionalidade**, sustentando-se a invalidade da tipificação penal da manifestação racista (esse raciocínio, ainda que não tenha expressado, parece ter

sido o adotado pelo Min. Marco Aurélio, vencido no julgamento). [48](#)

■ 14.10.5.3. Delação anônima

Em interessante julgado, o Min. Celso de Mello aduziu não ser possível a utilização da denúncia anônima, pura e simples, para a instauração de procedimento investigatório, por violar a vedação ao anonimato, prevista no art. 5.º, IV.

Em seu voto ele declara que “(...) os escritos anônimos **não** podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da *persecutio criminis*, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materializem o *crimen falsi*, p. ex.). Nada impede, contudo, que o Poder Público (...) provocado por **delação anônima** — tal como ressaltado por Nelson Hungria, na lição cuja passagem reproduzi em meu voto — adote **medidas informais** destinadas a apurar, previamente, em **averiguação sumária**, com **prudência** e **discrição**, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a **verossimilhança** dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da *persecutio criminis*, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas” (Inq. 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de Mello, j. 11.05.2005 — grifamos). [49](#)

Deixamos claro que referida decisão não afasta a importância e a constitucionalidade da delação anônima que, inclusive, vem sendo relevante instrumento para que a autoridade tome conhecimento do fato criminoso, bem como forte arma no combate à corrupção.

No último caso, destacamos o art. 13, item 2, da **Convenção das Nações**

Unidas contra a Corrupção, [50](#) ao estabelecer que “cada Estado-Parte adotará medidas apropriadas para garantir que o público tenha conhecimento dos órgãos pertinentes de luta contra a **corrupção** mencionados na presente Convenção, e facilitará o acesso a tais órgãos, quando proceder, para a **denúncia, inclusive anônima**, de quaisquer incidentes que possam ser considerados constitutivos de um delito qualificado de acordo com a presente Convenção”.

■ 14.10.5.4. “**Marcha da maconha**”

Ressaltamos a importante decisão do STF sobre a constitucionalidade da “**marcha da maconha**”, que consistia em eventos nos quais havia manifestação no sentido da descriminalização da droga (no caso, a maconha).

O STF, em 15.06.2011, por 8 x 0, no julgamento da **ADPF 187**, considerou legítimo o movimento, encontrando respaldo nos direitos fundamentais de **livre manifestação do pensamento** (art. 5.º, IV) e de **reunião** (art. 5.º, XVI), assegurando, inclusive, o **direito das minorias**, no sentido de se evidenciar a função contramajoritária da Corte.

Ainda, a manifestação evidenciava a “interconexão entre as **liberdades constitucionais de reunião** — direito-meio — e de **manifestação do pensamento** — direito-fim” (*Inf. 631/STF*).

De acordo com o entendimento do STF, “**a mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal não se confundiria com ato de incitação à prática do crime, [51](#) nem com o de apologia de fato criminoso. [52](#)** Concluiu-se que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas ou de proposta abolicionista a outro tipo penal, não significaria ilícito penal, mas, ao contrário, representaria o **exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião**” (*Inf. 631/STF*).

Assim, foi dada interpretação conforme a Constituição, com efeito vinculante, ao art. 287 do CP, afastando qualquer interpretação que caracterizasse a criminalização da manifestação de pensamento no sentido da descriminalização

das drogas, mesmo que em eventos públicos.

O Min. Luiz Fux, contudo, estabeleceu interessantes parâmetros, tais como:

- a **reunião** deve ser **pacífica**, sem armas, previamente noticiada às autoridades públicas quanto à data, ao horário, ao local e ao objetivo, e sem incitação à violência;
- **não se pode admitir a incitação, incentivo ou estímulo** ao **consumo** de entorpecentes na sua realização;
- naturalmente, **não poderá haver consumo de entorpecentes** na ocasião da manifestação ou evento público;
- nas manifestações, está **proibida a participação de crianças e adolescentes**.

O Min. Cezar Peluso, por sua vez, sustentou que a **liberdade de expressão** emana, diretamente, da **dignidade da pessoa humana** e se caracteriza como importante elemento para **formação e aprimoramento da democracia**. “Desse ponto de vista, (a liberdade de expressão) é um fator relevante da construção e do resguardo da democracia, cujo pressuposto indispensável é o pluralismo ideológico”, disse. Ele acrescentou que a **liberdade de expressão ‘só pode ser proibida quando for dirigida a incitar ou provocar ações ilegais iminentes’**” (*Notícias STF*, 15.06.2011).

Cabe lembrar que o STF, em outra oportunidade, no julgamento da **ADI 4.274**, ao analisar o art. 33, § 2.º, da Lei n. 11.343/2006, **53** também seguiu o mesmo entendimento firmado na ADPF 187, dando interpretação conforme a Constituição para “**excluir** qualquer significado que ensejasse a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou da legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas faculdades psicofísicas” e, claro, dentro dos limites já colocados no julgamento anterior (cf. *Inf. 649/STF*, j. 23.11.2011).

Na verdade, o posicionamento do STF encontra fundamento nas **garantias** dos **direitos à informação** e de **liberdade de expressão**, viabilizados pelo

direito de reunião e como **emanação dos princípios da dignidade da pessoa humana**, da **democracia** e da **cidadania**.

■ 14.10.6. Liberdade de consciência, crença e culto (art. 5.º, VI a VIII)

■ 14.10.6.1. Regras gerais

Assegura-se a inviolabilidade da **liberdade de consciência** e de **crença**, sendo assegurado o livre-exercício dos **cultos religiosos** e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (como o serviço militar obrigatório, nos termos do art. 143, §§ 1.º e 2.º) e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva é assegurada nos termos da lei.

Partindo dessa premissa, achamos interessante apontar alguns de seus desdobramentos:

- **ensino religioso nas escolas;**
- **feriados religiosos;**
- **casamento perante autoridades religiosas;**
- **transfusão de sangue nas Testemunhas de Jeová;**
- **curandeirismo;**
- **fixação de crucifixos em repartições públicas;**
- **imunidade religiosa;**
- **guarda sabática;**
- **a expressão “Deus seja louvado” nas cédulas de real.**

Na jurisprudência do STF, o tema passou a ser analisado quando se

questionou sobre a obrigatoriedade ou não da expressão “*sob a proteção de Deus*” no preâmbulo das Constituições estaduais.

Como se sabe, desde o advento da República (Decreto n. 119-A, de 07.01.1890), há separação entre Estado e Igreja, sendo o Brasil um país **leigo, laico** ou **não confessional**, não existindo, portanto, nenhuma religião oficial da República Federativa do Brasil. Apesar dessa realidade, a CF/88 foi promulgada “*sob a proteção de Deus*”, conforme se observa no preâmbulo do texto de 1988.

Todas as Constituições pátrias, exceto as de 1891 e 1937, invocaram a “*proteção de Deus*” quando promulgadas. Em âmbito estadual essa realidade se repetiu, com exceção do Estado do **Acre**. Referida omissão foi objeto de questionamento no STF pelo Partido Social Liberal. O STF, definindo a questão, além de estabelecer e declarar a **irrelevância jurídica do preâmbulo**, assinalou que a invocação da “*proteção de Deus*” **não é norma de reprodução obrigatória** na Constituição Estadual (ADI 2.076-AC, Rel. Min. Carlos Velloso). [54](#)

O preâmbulo não tem relevância jurídica, não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória; serve, apenas, como **norte interpretativo das normas constitucionais**. Por essas características e, ainda, por ser o Estado brasileiro laico, podemos afirmar que a invocação à divindade não é de reprodução obrigatória nos preâmbulos das Constituições Estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios. Conforme aprofundamos no *item 3.10.1.3*, o Brasil é um país **leigo, laico** ou **não confessional, lembrando que Estado laico não significa Estado ateu**.

Partindo dessa interpretação, o art. 5.º, VI, da CF/88 enaltece o **princípio da tolerância** e o **respeito à diversidade**.

Anota José Afonso da Silva que “na liberdade de crença entra a *liberdade de escolha* da religião, a *liberdade de aderir* a qualquer seita religiosa, a *liberdade* (ou o *direito*) de *mudar de religião*, mas também compreende a liberdade de *não aderir a religião alguma*, assim como a *liberdade de descrença*, a *liberdade de ser ateu* e de exprimir o agnosticismo”. [55](#)

Nesse contexto, outro dia, certo aluno em uma palestra indagou: “professor,

então, será que não seria possível eu fumar muita maconha, mas muita maconha mesmo, professor, e, quando estiver já bem fora de mim, eu cheiraria muita cocaína e, assim, em estado de êxtase, encontraria Deus, o meu Deus, professor?”.

Foi quando respondemos trazendo um caso concreto que havia sido noticiado: uma pessoa, em verdadeiro ritual, orientado por uma vidente e alegando crença religiosa, havia **sacrificado** crianças recém-nascidas para oferecer o sangue à “divindade”. Então perguntei ao aluno: será que, assim como cheirar cocaína ou fumar maconha, poderia aquela pessoa ter praticado o homicídio?

Não há dúvida de que o direito fundamental da liberdade de crença, da liberdade de culto e suas manifestações e prática de ritos **não** é absoluto. Um direito fundamental vai até onde começa outro e, diante de eventual colisão, ponderando interesses, um deverá prevalecer em face do outro, se não for possível harmonizá-los.

É claro que, na primeira situação, a liberdade de culto **não** pode justificar o consumo de droga ilícita, assim como, no segundo exemplo, o homicídio, com todas as suas qualificadoras, está configurado.

O tema é extremamente palpitante e vários outros desdobramentos podem ser estudados.

■ 14.10.6.2. *Ensino religioso nas escolas*

O art. 210, § 1.º, estabelece que o ensino religioso, de **matrícula facultativa**, constituirá disciplina dos horários normais das **escolas públicas de ensino fundamental**.

Dessa forma, uma escola não poderá reprovar aluno pelo fato de não frequentar a aula de ensino religioso, já que o **ensino religioso** será de matrícula **facultativa** e, a nosso ver, muito embora o texto fale apenas em “escola pública”, em razão na natureza do ensino, deve ser aplicado também às particulares.

■ 14.10.6.3. *Feriados religiosos*

Lembramos que, quando da vinda do Papa Bento XVI, no ano de 2007, para o Brasil, pretendia-se declarar *11 de maio*, dia da **canonização** de Frei Galvão, **feriado religioso**.

A matéria foi bastante discutida no Congresso Nacional e, ao final, a Lei n. 11.532, de 25.10.2007, sem conotação religiosa, acabou instituindo o dia 11 de maio como o *Dia Nacional do Frei Sant'Anna Galvão*, passando referida data a constar oficialmente no **calendário histórico-cultural brasileiro**, mas não se reconhecendo, em razão da laicidade, o feriado religioso. E como ficam os feriados religiosos que já constam de nosso calendário? A única resposta para esse questionamento é afirmar o seu caráter **histórico-cultural**.

■ 14.10.6.4. *Casamento perante autoridades religiosas*

O casamento é civil e gratuita a celebração (art. 226, § 1.º).

O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei (art. 226, § 2.º).

Portanto, se, conforme visto, não existe religião oficial e se a liberdade de crença religiosa está assegurada, podemos afirmar que o casamento em **centro espírita** ou mesmo em **templo, catedral, sinagoga, terreiro, casa religiosa**, enfim, o casamento celebrado por **líder de qualquer religião ou crença** tem o mesmo efeito civil do casamento realizado na religião católica, aplicando-se, por consequência, o art. 226, § 2.º.

O STF ainda não enfrentou o tema. Contudo, há importantes julgados proferidos por Tribunais de Justiça, como o da Bahia (MS 34.739-8/2005) e o do Rio Grande do Sul (AC 70003296555, 8.ª C. Cív., Rel. Des. Rui Portanova, j. 27.06.2002) no sentido de dar o correto efeito civil.

■ 14.10.6.5. *Transfusão de sangue nas Testemunhas de Jeová*

Não deve ser reconhecido o *crime de constrangimento ilegal* (art. 146, § 3.º,

I, do CP) na hipótese das **testemunhas de Jeová** se estiver o médico diante de **urgência** ou **perigo iminente**, ou se o paciente for **menor de idade**, pois, fazendo uma ponderação de interesses, não pode o direito à vida ser suplantado diante da liberdade de crença, até porque a Constituição não ampara ou incentiva atos contrários à vida.

Segundo noticiado pela Assessoria de Comunicação Social do TRF1, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2009.01.00.010855-6/GO (26.02.2009), o Desembargador Federal Fagundes de Deus “... registrou que no confronto entre os princípios constitucionais do direito à vida e do direito à crença religiosa importa considerar que atitudes de repúdio ao direito à própria vida vão de encontro à ordem constitucional — interpretada na sua visão teleológica. Isso posto, exemplificou o magistrado que a legislação infraconstitucional **não admite a prática de eutanásia e reprime o induzimento ou auxílio ao suicídio**. Dessa forma, entende o magistrado que deve prevalecer ‘o direito à vida, porquanto o direito de nascer, crescer e prolongar a sua existência advém do próprio direito natural, inerente aos seres humanos, sendo este, sem sombra de dúvida, primário e antecedente a todos os demais direitos’”.

■ 14.10.6.6. **Curandeirismo**

O art. 284 do Código Penal tipifica o exercício do **curandeirismo**, que é crime contra a *saúde pública*:

- prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;
- usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;
- fazendo diagnósticos.

O tema ainda não chegou ao STF, mas, conforme vem sendo decidido por alguns tribunais estaduais, em casos concretos e específicos, não estará configurado o crime se a promessa de cura decorrer de crença religiosa e dentro

de um contexto individual de razoabilidade.

■ 14.10.6.7. *Crucifixos em repartições públicas*

Outro ponto bastante polêmico foi a questão dos **crucifixos** em repartições públicas. Como admiti-los diante da regra de ser o Brasil um país leigo, laico ou não confessional? A única “saída”, que vem sendo adotada por algumas decisões (cf. Pedidos de Providências ns. 1.344, 1.345, 1.346 e 1.362/CNJ, no âmbito do Judiciário, j. 29.05.2007), é a ideia de se tratar de **símbolo cultural**, e não religioso.

O entendimento, reconhecemos, não se mostra convincente, tanto é assim que uma das determinações do *Presidente do TJ/RJ*, em sua posse em 03.02.2009, foi a retirada dos crucifixos e a desativação da capela.

Ainda, também em contraposição ao decidido pelo CNJ, o *Conselho da Magistratura do TJRS*, no julgamento do processo n. 0139-11/000348-0, em 06.03.2012, determinou fossem retirados os crucifixos e símbolos das dependências do TJRS.

Contra essa decisão, foi instaurado no **CNJ** o PP 0001058-48.2012.2.00.0000, que está sendo julgado em conjunto com o PCA 0001418-80.2012.2.00.0000. Incluído na pauta de 11.02.2014, foi adiado em razão do término da sessão. [56](#) Dessa forma, o CNJ poderá rediscutir a matéria, revendo o posicionamento anteriormente estabelecido em 2007.

■ 14.10.6.8. *Imunidade religiosa*

Contempla o art. 150, VI, “b”, a denominada **imunidade religiosa** ao estabelecer, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, a vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de instituir **impostos** sobre templos de qualquer culto (*assunto que deve ser aprofundado em direito tributário*).

Essa regra se mostra de grande relevância, pois impede que o Estado utilize,

eventualmente, de seu poder de tributar para *embaraçar o funcionamento dos cultos religiosos ou igrejas* (art. 19, I).

Conforme estabeleceu o STF, “a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘b’, CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’. O § 4.º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso VI do art. 150 da CF...” (RE 325.822, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 15.12.2002, Plenário, *DJ* de 14.05.2004).

Isso posto, surge a questão: **a maçonaria tem imunidade tributária religiosa?**

Não.

Decidiu o Min. Ricardo Lewandowski, acompanhado pela unanimidade dos Ministros do STF, que “... a maçonaria é uma ideologia de vida e **não uma religião**, assim, a entidade não poderia ser isenta de pagar o IPTU. Segundo ele, a prática maçom não tem dogmas, não é um credo, é uma **grande família**. ‘Ajudam-se mutuamente aceitando e pregando a ideia de que o homem e a humanidade são passíveis de melhoria, aperfeiçoamento. Como se vê é uma grande confraria que antes de mais nada prega e professa uma filosofia de vida, apenas isso’, disse” (*Notícias STF*, 13.04.2010. Cf., também, *Inf.* 582/*STF* — **RE 562.351**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.09.2012, 1.ª T., *DJE* de 14.12.2012).

■ 14.10.6.9. *Guarda sabática*

Outro ponto polêmico é a obrigatoriedade ou não de o Estado ter de **designar data alternativa** para a realização de concursos públicos quando a data da prova tiver sido fixada em dias que devam ser guardados, como acontece com os **Adventistas do Sétimo Dia** (*sábado* — dia de repouso e de culto) e com os **Judeus** (*Shabat* — do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado).

O tema está para ser aprofundado pelo STF no julgamento da **ADI 3.714**,

ajuizada em 20.04.2006 pela *Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen)*, contra a Lei paulista n. 12.142/2005, que assegura a “guarda sabática” se houver alegação de motivo de crença religiosa (convém lembrar que, apesar de a referida lei ter sido totalmente vetada pelo Governador do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa derrubou o veto, restabelecendo o ato normativo) **(matéria pendente de julgamento pelo STF)**.

A questão foi retomada, no julgamento da **STA 389, 57** que buscava a suspensão do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) marcado para os dias 5 e 6 de dezembro de 2009.

O STF, por maioria, manteve o dia da prova e não fixou dia alternativo, até porque, no edital, havia a possibilidade de pedido de “atendimento a necessidades especiais”, além do que a prova poderia ser realizada no mesmo dia, após as 18h, caso em que deveriam os candidatos que guardam os sábados, contudo, apresentar-se com os demais, ficando isolados e aguardando para a realização da prova.

O STF, naquele momento, entendeu que a previsão regimental era suficiente e, então, não determinou a designação de dia alternativo (vencido o Min. Marco Aurélio).

Essa tem sido a “saída” de alguns concursos que permitem a realização da prova após as 18h do sábado, mas exigem que os candidatos permaneçam isolados e no local, devendo apresentar-se no dia marcado para todos (para se ter um exemplo, o vestibular da *Universidade do Estado do Amazonas — UEA*, 2012, organizado pela VUNESP, estabeleceu essa regra de **confinamento**).

O tema ainda vai ser definido pelo STF, mas, para nós, ante o risco de provas com graus distintos e possíveis favorecimentos de um lado ou do outro, parece que essa tem sido a melhor alternativa, pelo menos em uma análise inicial. Vamos aguardar a decisão do STF, e ainda estamos refletindo sobre esse palpitante assunto!

■ 14.10.6.10. A expressão “Deus seja louvado” nas cédulas de real

Em ação civil pública ajuizada pelo MPF/SP em face da União e do BACEN, pretende-se a condenação dos réus à obrigação de fazer consubstanciada na retirada da expressão “**Deus seja louvado**” das cédulas de dinheiro nacional.

O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e os autos encontravam-se, no momento do *fechamento desta edição*, no TRF3. [58](#)

O tema é bastante interessante e achamos que a decisão de primeira instância de não acolher o pedido está correta, pois, muito embora o Brasil seja um país laico, isso não significa um Estado ateu. O que se exige do Estado brasileiro e decorre da noção de laicidade (contraposta ao laicismo — cf. *item 3.10.1.3*) é a neutralidade, o respeito ao pluralismo, e não a atitude de intolerância e de hostilidade.

■ **14.10.6.11. Aspectos conclusivos**

Dentro de uma ideia de **bom senso**, **prudência** e **razoabilidade**, a Constituição assegura a todos o direito de aderir a qualquer crença religiosa, ou recusá-las, ou, ainda, de seguir qualquer corrente filosófica, ou de ser ateu e exprimir o agnosticismo, garantindo a liberdade de descrença ou a mudança da escolha já feita.

Portanto, não podemos discriminar ou reprimir. O preconceito deve ser afastado, a sociedade tem de conviver e se harmonizar com as escolhas antagônicas sem que o radicalismo egoísta suplante a liberdade constitucionalmente assegurada.

■ **14.10.7. Liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Indenização em caso de dano (art. 5.º, IX e X)**

É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Veda-se a censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, § 2.º), porém, apesar da liberdade de expressão acima garantida, lei federal deverá

regular as diversões e os espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

Deverá, outrossim, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (art. 220, § 3.º, I e II).

Se, durante as manifestações acima expostas, houver violação da intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas, será assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação (art. 5.º, X).

Selecionamos três temas importantes já apreciados pelo STF, estando um outro pendente:

■ **ADPF 130 — “Lei de Imprensa”** — *j. 30.04.2009*: o STF entendeu que a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) não foi recepcionada pelo novo ordenamento, uma vez que marcada por aspectos não democráticos;

■ **ADI 4.451 — “Lei Eleitoral sobre o Humor”** — *j. 02.09.2010*: o STF entendeu, referendando a liminar do Min. Ayres Britto, que o art. 45, II e III, e §§ 4.º e 5.º da Lei n. 9.504/97 (*Lei das Eleições*) violam a **liberdade de imprensa**, visto que o **humor** pode ser considerado **imprensa**. Referidos dispositivos afrontam, também, a **plena liberdade de informação jornalística**, nos termos do **art. 220, § 1.º**, da CF/88. Ainda, a manifestação, mesmo que seja pelo humor, não pode ser restringida, já que ela instrumentaliza e permite o direito de crítica, de opinião (**mérito pendente de julgamento pelo STF**). Nesse sentido:

“EMENTA: A **liberdade de imprensa** assim abrangentemente livre não é de sofrer constrictões em período eleitoral. Ela é plena em todo o tempo, lugar e circunstâncias. Tanto em período não eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. **Se podem as emissoras de rádio e televisão, fora do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que**

envolvam partidos políticos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral” (ADI 4.451-MC-REF).

■ **ADI 4.815 — “Biografias não autorizadas”:** ação movida pela *Associação Nacional dos Editores de Livros (ANEL)*. O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, em 10.06.2015, julgou procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os **direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, de produção científica, de liberdade de informação e de proibição de censura** (CF, arts. 5.º, IV, V, IX, X e XIV; e 220), declarar **inexigível** o **consentimento** de **pessoa biografada** relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas). Ainda, reafirmando o **direito à inviolabilidade da intimidade**, da **privacidade**, da **honra** e da **imagem da pessoa**, nos termos do art. 5.º, X, CF/88, deixou claro que em caso de transgressão haverá o direito de resposta proporcional ao agravo e o dever de indenizar, podendo-se pensar, em último caso, também na responsabilidade penal, nos termos da lei.

■ **ARE 833.248 — “Direito ao Esquecimento”:** o STF vai analisar o denominado “direito ao esquecimento” na esfera civil, discutindo a possibilidade de serem reavivados fatos criminosos do passado e que já teriam sido esquecidos pela sociedade. No caso concreto, em 2004, o programa “Linha Direta Justiça”, da TV Globo, veiculou informações sobre homicídio praticado em 1958 e que, à época, teve grande repercussão social. Discute-se a colisão entre os princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade.

■ **14.10.8. Intimidade e vida privada e o sigilo bancário (art. 5.º, X)**

De acordo com o art. 5.º, X, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Passemos a analisar, então, o importante tema da **intimidade** e da **vida privada** e a **quebra de sigilo bancário**.

O STF determinou a necessidade de **autorização judicial** para a quebra do sigilo bancário no julgamento do **RE 389.808** (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.12.2010, Plenário, *DJE* de 10.05.2011).

A discussão surgiu em razão de comunicado feito pelo *Banco Santander* a determinada empresa, informando que a Delegacia da Receita Federal do Brasil, partindo de *mandado de procedimento fiscal* e com base na LC n. 105/2001, havia solicitado àquela instituição financeira a entrega de informações sobre movimentação bancária da empresa durante o período de 1998 a julho de 2001.

Diante dessa notícia, a empresa buscou o Judiciário e, após várias medidas, a decisão final coube ao STF, que, no caso concreto, estabeleceu a necessidade de **autorização judicial** para a quebra de sigilo bancário, por se tratar de verdadeira **cláusula de reserva de jurisdição**, não tendo, portanto, o Fisco esse poder.

Em seu voto, o Min. Celso de Mello fala em um verdadeiro “**‘estatuto constitucional do contribuinte’** — consubstanciador de direitos e limitações **oponíveis ao poder impositivo** do Estado”, destacando-se, no caso, o **direito à intimidade** e à **privacidade**.

Celso de Mello afirma, ainda, que as garantias não são absolutas. Aliás, nenhum direito e garantia fundamental é absoluto, devendo, na hipótese de colisão, ser feito juízo de **ponderação**.

Portanto, para eventual quebra de sigilo bancário, é imprescindível “... a existência de **causa provável**, vale dizer, de **fundada suspeita** quanto à ocorrência de fato cuja apuração resulte exigida pelo interesse público. Na realidade, sem **causa provável**, não se justifica, sob pena de inadmissível consagração do arbítrio estatal e de inaceitável opressão do indivíduo pelo Poder Público, a ‘*disclosure*’ das contas bancárias, eis que a **decretação da quebra**

do sigilo não pode converter-se num instrumento de indiscriminada e ordinária devassa da vida financeira das pessoas em geral”.

E, ao final, conclui o Ministro Celso de Mello: “... entendo que a *decretação da quebra do sigilo bancário*, ressalvada a **competência extraordinária das CPI’s (CF, art. 58, § 3.º)**, pressupõe, sempre, a existência de **ordem judicial**, sem o que não se imporá à instituição financeira o dever de fornecer, seja à *administração tributária*, seja ao *Ministério Público*, seja, ainda, à *Polícia Judiciária*, as informações que lhe tenham sido solicitadas”.

Assim, podemos esquematizar:

■ **possibilidade de quebra do sigilo bancário:** o Poder Judiciário e as CPIs, que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (cf. aprofundamento no *item 9.8.3.14*);

■ **não podem quebrar o sigilo bancário, devendo solicitar autorização judicial:** Administração Tributária, Ministério Público e Polícia Judiciária.

Por todo o exposto, a tendência do STF é manter, conforme estudado nos precedentes citados e como já vinha julgando, a quebra do sigilo bancário não somente pelo Judiciário como, também, pela **CPI** (sendo que, nesse caso, haveria transferência de sigilo, devendo a CPI e seus integrantes responsabilizar-se pela **manutenção do sigilo**, só podendo utilizar as informações nos limites de sua atuação e nos termos da lei e da Constituição, sob pena de serem responsabilizados).

■ **14.10.9. Inviolabilidade domiciliar (art. 5.º, XI)**

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar **sem o consentimento** do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”; ou seja, sem o consentimento do morador só poderá nela penetrar:

■ **por determinação judicial:** [59](#) somente durante o **dia**;

■ **em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro:** poderá penetrar sem o consentimento do morador, durante o **dia** ou à **noite**, não necessitando de determinação judicial.

O que deve ser entendido por dia ou noite? Concordamos com Alexandre de Moraes que o melhor critério seria conjugar a definição de parte da doutrina (das 6 às 18h) com a posição de Celso de Mello, que utiliza um critério físico-astronômico: a **aurora** e o **crepúsculo**. [60](#)

E o que devemos entender por casa? Segundo a doutrina e a jurisprudência, casa abrange não só o domicílio, como também o escritório, oficinas, garagens etc. (RT 467/385), ou, até, os quartos de hotéis. Vejamos:

“Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5.º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4.º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Doutrina. Precedentes. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5.º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (*invito domini*), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. Doutrina. Precedentes (STF)” (RHC 90.376, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.04.2007, DJ de 18.05.2007).

■ **14.10.10. Sigilo de correspondência e comunicações (art. 5.º, XII)**

“É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.” Vejamos:

■ **sigilo de correspondência:** como regra, o sigilo de correspondência é inviolável, salvo nas hipóteses de decretação de estado de defesa e de sítio,

quando poderá ser restringido (arts. 136, § 1.º, I, “b”, e 139, III). Cumpre observar, também, que esse direito não é absoluto e poderia, de acordo com a circunstância do caso concreto, ser afastado, por exemplo, na interceptação de uma carta enviada por sequestradores. A suposta prova ilícita convalida-se em razão do exercício da legítima defesa;

■ **sigilo das comunicações telegráficas:** também inviolável, salvo nas hipóteses de decretação de estado de defesa e de sítio, que poderá ser restringido (arts. 136, § 1.º, I, “c”, e 139, III);

■ **sigilo bancário (comunicação de dados):** no tocante ao **sigilo bancário**, o art. 38 (parcialmente recepcionado) da Lei n. 4.595/64, que foi recepcionada pela CF/88, com *status* de lei complementar (art. 192, *caput*), permitia a quebra do sigilo bancário por: autorização judicial, determinação de CPI (art. 58, § 3.º), ou requisição do Ministério Público (art. 129, VI), para objeto de investigação criminal. Referido art. 38 foi expressamente **revogado** pela **LC n. 105, de 10.01.2001**, que passou a disciplinar as regras sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Além das regras anteriores, o art. 6.º da LC n. 105/2001, inovando, permitiu às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **examinar** documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, **quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis** pela autoridade administrativa competente, devendo o resultado dos exames, as informações e os documentos ser **conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Mencionada regra foi regulamentada pelo Decreto n. 3.724, de 10.01.2001**, cujo art. 1.º, § 1.º, estabelece que o procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica denominada **Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)**, instituído em ato da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3.º e 4.º do aludido artigo. O art. 4.º, § 1.º, do decreto estabelece, ainda, que a requisição será formalizada mediante documento denominado **Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)** e será dirigida, conforme o caso, ao: **a)** Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto; **b)** Presidente da Comissão de Valores

Mobiliários, ou a seu preposto; **c)** presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto; **d)** gerente de agência. O que se percebe, então, pela nova regra, é a quebra de sigilo bancário pela própria Receita Federal, dispensando-se o requerimento ao Poder Judiciário, o que, em nosso entender, **fere o art. 5.º, X e XII**, sendo a aludida LC indiscutivelmente inconstitucional, atribuindo um direito não estabelecido pelo constituinte originário (**CAUIDADO:** o tema está sendo discutido nas ADIs 2.859-6, 2.406, 2.389, 2.386, 2.397 e 2.390). Contudo, conforme visto no *item 14.10.8*, o STF declarou a necessidade de **autorização judicial** para a quebra de sigilo bancário (**RE 389.808**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.12.2010, Plenário, *DJE* de 10.05.2011), tratando-se, assim, de **cláusula de reserva de jurisdição**. A CPI, por si, também poderá quebrar o sigilo bancário, devendo haver transferência de sigilo;

■ **quebra de sigilo e Ministério Público:** na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — CPMI dos Correios, o STF considerou *ilegal* o pedido de quebra feito diretamente pelo MP. Assim, estabeleceu que a prova utilizada pelo MP tem de vir de CPI ou de autorização do juiz (Inq. 2.245, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.08.2007, *DJ* de 09.11.2007 — dada a sua importância, recomendamos a leitura);

■ **sigilo fiscal (comunicação de dados):** no tocante ao **sigilo fiscal**, faculta-se à administração tributária identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte (art. 145, § 1.º). Assim, deve haver expressa individualização do investigado e do objeto da investigação e a indispensabilidade dos dados em poder da Receita Federal. De acordo com o art. 198, *caput*, do CTN, em regra, deve ser precedida de autorização judicial, sendo, portanto, expedida por solicitação de CPI e do Ministério Público. Além dessas situações, destacamos a **LC n. 104, de 10.01.2001**, que, trazendo novidade à regra existente e alterando o CTN, agora permite a divulgação pela Fazenda Pública por simples solicitação de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, havendo a necessidade de ser comprovada a instauração de **regular processo administrativo**, com o objetivo de investigar o sujeito passivo. Essa nova regra, todavia, pelos mesmos motivos acima expostos, entendemos

inconstitucional. Resta aguardar o posicionamento do STF sobre o assunto. Conforme visto, seguindo o entendimento do STF no julgamento do **RE 389.808**, a tendência é afirmar também a necessidade de autorização judicial para a quebra ou em razão de ato de CPI;

■ **sigilo das comunicações telefônicas:** a quebra será permitida nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Assim, o procedimento deverá seguir as regras traçadas pela Lei n. 9.296/96, sob pena de constituir prova obtida por meio ilícito (art. 5.º, LVI); [61](#)

■ ***habeas corpus*:** “O *habeas corpus* é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, haja vista a possibilidade destes resultarem em constrangimento à liberdade do investigado (...)” (AI 573.623, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31.10.2006, *Inf. 447/STF*);

■ **comunicações em meios eletrônicos:** a garantia constitucional da inviolabilidade abrange, naturalmente, as comunicações privadas também em meios eletrônicos, pela *internet*, pelos tradicionais *e-mails* ou ainda pelos meios de comunicações proporcionados pelas redes sociais, como *direct message* (DM) no *Twitter*, *Instagram Direct*, conversas privadas por meio de *WhatsApp*, *Facebook* etc. No caso, destacamos a regulamentação da matéria no denominado **marco civil da internet**, qual seja, a **Lei n. 12.965/2014** que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da *internet* no Brasil e determinou as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.

■ 14.10.11. Liberdade de profissão (art. 5.º, XIII)

A Constituição assegura a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a **lei estabelecer**. Trata-se, portanto, de norma constitucional de eficácia contida, podendo lei infraconstitucional limitar o seu alcance, fixando condições ou requisitos para o pleno exercício da profissão.

É o que acontece com o **Exame de Ordem** (art. 8.º, IV, da Lei n. 8.906/94), cuja aprovação é um dos requisitos essenciais para que o bacharel em direito possa inscrever-se junto à OAB como advogado e que, inclusive, foi declarado **constitucional** pelo STF no julgamento do **RE 603.583** (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2011, Plenário, *DJE* de 25.05.2012, com repercussão geral, *Inf.* 646/STF e *item 12.5.3*, deste trabalho).

Outro tema interessante está relacionado à exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Em **17.06.2009**, por 8 x 1, o STF **derrubou esse requisito** (cf. RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.06.2009, Plenário, *DJE* de 13.11.2009 e *item 19.7.1*).

Cabe observar que tramita no Senado Federal a **PEC n. 33/2009** que, com algumas ressalvas, passa a exigir o diploma de jornalista (**matéria pendente**). Assim, no momento da leitura, checar se referida PEC foi aprovada.

Em outro precedente interessante, o STF entendeu que a **profissão de músico** não exige a inscrição em conselho de fiscalização, deixando claro essa necessidade apenas quando houver potencial lesivo na atividade. **A regra, portanto, é a liberdade**, e, ademais, a atividade de músico encontra garantia na liberdade de expressão, enquanto manifestação artística (cf. **RE 414.426**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.08.2011, Plenário, *DJE* de 10.10.2011).

Finalmente, dentre tantos outros julgados, destacamos, *especialmente para as provas da importante carreira da defensoria pública*, aquele segundo o qual o STF analisou a suposta prática do *delito de exercício ilegal da profissão* por parte de “**flanelinhas**”, denunciados com base no art. 47 da Lei das Contravenções Penais, por não preencherem as condições estabelecidas na Lei n. 6.242/75, que, regulamentando o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores, exige o registro na Delegacia Regional do Trabalho competente.

Conforme entendeu a 2.ª T. do STF, a não observância da “disposição legal pelos pacientes não gerou lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma, bem como não revelou elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual é aplicável, à hipótese dos autos, o **princípio da insignificância**”, levando ao

reconhecimento do **crime de bagatela**. Assim, a ordem foi concedida para cassar o acórdão do STJ (HC 239.643) que determinou o prosseguimento da ação penal e restabelecer a sentença de primeiro grau que rejeitou a denúncia, em face da atipicidade da conduta imputada (**HC 115.046**, j. 19.03.2013).

■ 14.10.12. Liberdade de informação (art. 5.º, XIV e XXXIII)

É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Trata-se do direito de informar e de ser informado.

Completando tal direito fundamental, o art. 5.º, XXXIII, estatui que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Regulando o acesso a informações previsto no art. 5.º, XXXIII, temos a **Lei n. 12.527, de 18.11.2011**, com *vacatio legis* de 180 dias. [62](#)

Dentro do tema da liberdade de informação, pedimos vênia para citar interessante decisão do Ministro Gilmar Mendes — envolvendo a exigência do **exame psicotécnico** em concursos públicos, lembrando que, de acordo com a **SV 44**, “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” (j. 08.04.2015):

“... Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: ‘Administrativo. Constitucional. Concurso público. Exame psicotécnico. Sigilo e irrecorribilidade do resultado. 1. A Constituição afasta de pronto o caráter sigiloso das decisões administrativas, em primeiro lugar porque a todos é assegurado o direito de exigir do órgão público o esclarecimento de situação de interesse pessoal, além do que é assegurada qualquer informação que seja do exclusivo interesse do cidadão, salvo quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado... A possibilidade de

interpretação errônea de dados psicológicos, eis que a Psicologia não é uma ciência absoluta em termos de fixação dos aspectos inerentes à personalidade e condições emocionais do indivíduo, não permite a ausência de possibilidade de reapreciação dos atos administrativos'. Alega-se violação aos artigos 1.º; 2.º; 5.º, XXXV, LIV, LV, LXIX; 18; 37, *caput* e I; e, 93, IX, da Carta Magna. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual o exame psicotécnico não pode ter critério sigiloso, sob pena de infringir o princípio da publicidade. Nesse sentido o RE 342.074, 2.ª T., Rel. Maurício Corrêa, *DJ* 17.09.2002, assim ementado: 'EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Concurso público. Exame psicotécnico. Exame psicotécnico com caráter eliminatório. Avaliação realizada com base em critérios não revelados. Ilegitimidade do ato, pois impede o acesso ao Poder Judiciário, para conhecer de eventual lesão ou ameaça de direito ocasionada pelos critérios utilizados. Agravo regimental a que se nega provimento'. No mesmo sentido o RE 243.926, 1.ª T., Rel. Moreira Alves, *DJ* 16.05.2000. Assim, nego seguimento ao recurso (art. 557, *caput*, do CPC/73). Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2003. Ministro Gilmar Mendes, Relator" (RE 348.494, *DJ* de 11.12.2003, p. 51).

Por fim, como será comentado adiante, a garantia da liberdade de informação é complementada pelo direito de obtenção de certidões fixado no art. 5.º, XXXIV, "b".

■ 14.10.13. Liberdade de locomoção (art. 5.º, XV e LXI)

A locomoção no território nacional em tempo de paz é livre, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nesse sentido, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5.º, LXI).

Esse direito poderá ser restringido na vigência de **estado de defesa**, quando se cria a possibilidade de prisão por crime de Estado determinada pelo executor

da medida (art. 136, § 3.º, I), exceção à regra acima exposta (flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente).

Também ocorrerá restrição à liberdade de locomoção na vigência do **estado de sítio**, nos termos do art. 139, I, podendo ser tomadas contra as pessoas (nas hipóteses do art. 137, I) medidas visando obrigá-las a permanecer em localidade determinada, bem como medidas restritivas também em caso de guerra declarada ou agressão armada estrangeira (art. 137, II).

■ 14.10.14. Direito de reunião (art. 5.º, XVI)

Garante-se o direito de reunião, de forma **pacífica, sem armas** e em **locais abertos ao público**, direito que poderá ser exercido independentemente de prévia autorização do Poder Público, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse prévio aviso é fundamental para que a autoridade administrativa tome as providências necessárias relacionadas ao trânsito, à organização etc.

Nesse sentido, podemos citar a discussão sobre a **“marcha da maconha”** (cf. *item 14.10.5.4*), que o STF analisou no julgamento da **ADPF 187** e da **ADI 4.224**.

Conforme visto, o direito de reunião é o “direito-meio” para se viabilizar a manifestação do pensamento no sentido da descriminalização da droga, claro, dentro dos limites que a Corte fixou e já foram apontados no referido item, ao qual remetemos nosso ilustre leitor para aprofundamento.

Finalmente, é de lembrar que, ainda que exercido no seio das associações, o direito de reunião poderá ser restringido na vigência de estado de defesa (art. 136, § 1.º, I, “a”), podendo ser suspensa a liberdade de reunião durante o estado de sítio (art. 139, IV).

■ 14.10.15. Direito de associação (art. 5.º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI)

A liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, é **plena**. Portanto, ninguém poderá ser compelido a associar-se e, uma vez associado, será livre, também, para decidir se permanece associado ou não.

A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Têm elas autonomia para formular seus estatutos.

A única forma de se dissolver compulsoriamente uma associação já constituída será mediante **decisão judicial transitada em julgado**, na hipótese de finalidade ilícita.

Também a suspensão de suas atividades se dará por decisão judicial, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado; pode-se implementá-la por meio de provimentos antecipatórios ou cautelares.

Quando **expressamente autorizadas**, as entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, podendo, como substitutas processuais, defender, em nome próprio, o direito alheio de seus associados.

Conforme estabeleceu o STF, a simples previsão estatutária de autorização geral para a associação é **insuficiente** para lhe conferir legitimidade ativa para a defesa de seus associados. Assim, tem sido exigida a **declaração expressa** “manifestada por **ato individual do associado** ou por **assembleia geral da entidade**. Por conseguinte, somente os associados que apresentaram, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva” (**RE 573.232**, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, j. 14.05.2014, Plenário, *DJE* de 19.09.2014).

■ 14.10.16. Direito de propriedade (art. 5.º, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI)

Como regra geral, assegura-se o direito de propriedade, que deverá atender à sua função social, nos exatos termos dos arts. 182, § 2.º, e 186 da CF/88.

Esse direito **não é absoluto**, visto que a propriedade poderá ser

desapropriada por necessidade ou utilidade pública e, desde que esteja cumprindo a sua função social, será paga justa e prévia indenização em dinheiro (art. 5.º, XXIV). Por outro lado, caso a propriedade não esteja atendendo a sua função social, poderá haver a chamada **desapropriação-sanção** pelo Município com pagamentos em títulos da dívida pública (art. 182, § 4.º, III) ou com títulos da dívida agrária, pela União Federal, para fins de reforma agrária (art. 184), não abrangendo, nesta última hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, e não tendo o seu proprietário outra, e a propriedade produtiva (art. 185, I e II).

No tocante à propriedade urbana, a desapropriação-sanção é a última medida, já que, primeiro, procede-se ao parcelamento ou edificação compulsórios e, em seguida, à imposição de IPTU progressivo no tempo, para, só então, passar-se à desapropriação-sanção.

Importante destacar, embora matéria a ser indagada normalmente nas provas de tributário, que até o advento da **EC n. 29/2000**, que deu nova redação ao § 1.º do art. 156, acrescentando-lhe dois incisos, o STF admitia a progressividade do IPTU **exclusivamente** para a hipótese do art. 182, § 4.º, II, entendimento esse, inclusive, pacificado na **S. 668/STF**: “é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, **antes da Emenda Constitucional 29/2000**, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”.[63](#)

Com a nova redação conferida ao art. 156, § 1.º, I e II, pela EC n. 29/2000, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4.º, II, o **IPTU** poderá ser **progressivo** em razão do **valor do imóvel** (*progressividade fiscal* — art. 145, § 1.º, c/c o art. 156, § 1.º, I) e ter **alíquotas diferentes**, de acordo com a **localização** e o **uso do imóvel**, dependendo, para esta última hipótese (art. 156, § 1.º, II), de caráter nitidamente *extrafiscal*, da **edição de plano diretor** estabelecendo as exigências fundamentais de ordenação da cidade.

Nessa linha, convém verificar a nova redação conferida ao art. 153, § 4.º, I, pela **Reforma Tributária** (EC n. 42/2003), explicitando a progressividade do

ITR.

O direito de propriedade, ainda, poderá ser restringido através de **requisição**, no caso de iminente perigo público, podendo a autoridade competente usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Lembramos, também, as limitações administrativas, as servidões e a expropriação. Nesse último caso, as **propriedades rurais e urbanas** de qualquer região do País onde forem localizadas **culturas ilegais de plantas psicotrópicas** ou a **exploração de trabalho escravo**, na forma da lei, serão **expropriadas** e destinadas à **reforma agrária** e a **programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei**, observado, no que couber, o disposto no art. 5.º. Ainda, todo e qualquer **bem de valor econômico** apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será **confiscado** e reverterá a **fundo especial com destinação específica**, na forma da lei (cf. **art. 243**, CF/88, na redação dada pela **EC n. 81/2014**).

Por fim, a garantia assegurada à pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, no sentido de não ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Para as provas de concursos, especialmente em matéria de *direito administrativo*, sugerimos um estudo mais aprofundado do tema **desapropriação** e suas diversas modalidades. Nesse sentido, regulamentando os arts. 182 e 183 da CF/88, foi elaborada a **Lei n. 10.257, de 10.07.2001**, denominada **Estatuto da Cidade**, que trouxe profundas inovações a respeito da matéria, refletindo inclusive no campo do direito civil, processual civil, na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei da Ação Civil Pública, para citar alguns exemplos. Dessa forma, sugerimos uma leitura atenta do referido dispositivo legal na preparação dos candidatos (obs.: a lei pode ser obtida no site <www.planalto.gov.br>).

■ 14.10.17. Direito de herança e estatuto sucessório (art. 5.º, XXX e XXXI)

Como corolário do direito de propriedade, o art. 5.º, XXX, garante o **direito de herança**.

Ensina Maria Helena Diniz que “o objeto da sucessão *causa mortis* é a herança, dado que, com a abertura da sucessão, ocorre a mutação subjetiva do patrimônio do *de cuius*, que se transmite aos seus herdeiros, os quais se subrogam nas relações jurídicas do defunto, tanto no ativo como no passivo até os limites da herança”.⁶⁴

O Ministro Maurício Corrêa observou que “... a Constituição garante o direito de herança, mas a forma como esse direito se exerce é matéria regulada por normas de direito privado” (ADI 1.715-MC/DF, DJ de 30.04.2004, p. 27). De fato, sobre esse assunto, remetemos o leitor para os compêndios de direito civil.

Por fim, a Constituição traz regra específica no art. 5.º, XXXI, sobre a *sucessão de bens de estrangeiros situados no País*, que será regulada pela lei brasileira em benefício do *cônjuge* ou dos *filhos brasileiros*, **sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do *de cuius***.

Ou seja, conforme anotou Celso de Mello, “a sucessão de estrangeiro domiciliado no Brasil rege-se-á, como é óbvio, pela lei brasileira (critério do *jus domicilii*). Contudo, se a lei nacional do *de cuius* estrangeiro, aqui domiciliado, for mais favorável ao cônjuge supérstite ou aos filhos brasileiros, aplicar-se-á aquele ordenamento jurídico (critério do *jus patriae*). De outro lado, não sendo, o *de cuius*, estrangeiro domiciliado no Brasil, nem o seu estatuto pessoal mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros, rege-se-á a sucessão dos bens aqui localizados pelo direito brasileiro (critério do *forum rei sitae*)... Isso significa que, em nosso direito, prevalece, como regra geral, o *princípio da unidade da sucessão ou do estatuto sucessório*. Os diversos elementos ou circunstâncias de conexão, já referidos, de natureza pessoal (*jus domicilii* e *jus patriae*) e real (*forum rei sitae*), tornam possível solucionar o problema dos conflitos de leis no espaço, ensejando, dessa forma, a aplicação do estatuto jurídico pertinente”.⁶⁵

■ 14.10.18. Propriedade intelectual (art. 5.º, XXVII, XXVIII e XXIX)

Os incisos em referência garantem o **direito de propriedade intelectual**, quais sejam, a **propriedade industrial** e os **direitos do autor**. A Constituição os define da seguinte maneira:[66](#)

■ aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

■ são assegurados, nos termos da lei: *a)* a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; *b)* o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

■ a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

■ 14.10.19. Defesa do consumidor (art. 5.º, XXXII)

Sem dúvida foi a **Constituição portuguesa** de 1976 que, de maneira pioneira, acolheu diversas normas de proteção aos consumidores. Essa realidade reflete, acima de tudo, a recente preocupação do Estado com os problemas da sociedade de massa, especialmente a partir do Estado Social de Direito.[67](#)

A **Constituição espanhola**, na mesma linha, buscando inspiração nas disposições da portuguesa, também, de modo amplo, tratou da proteção dos consumidores no art. 51:1.

Influenciada por ambas (portuguesa e espanhola), a Constituição Federal de 1988 assegurou **regras protetivas para o consumidor**, destacando-se os seguintes dispositivos legais:

■ **Art. 5.º, XXXII:** “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

■ **Art. 24:** “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) VIII — responsabilidade por dano ao meio ambiente, **ao consumidor**, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.

■ **Art. 129:** “São funções institucionais do Ministério Público: (...) III — promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

■ **Art. 150, § 5.º:** “A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”.[68](#)

■ **Art. 170:** “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V — **defesa do consumidor**”.

■ **Art. 48 (ADCT):** “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará **código de defesa do consumidor**”.

Conforme aponta José Afonso da Silva, muito embora reconheça a Constituição portuguesa como a pioneira no estabelecimento das regras protetivas dos consumidores, “(...) as constituições brasileiras, desde 1946, inscreveram um dispositivo que poderia servir de base à proteção do consumidor, se fosse eficaz. Referimo-nos à *repressão ao abuso de poder econômico*, que, na Constituição de 1988, aparece com enunciado menos eficaz ainda, porque o fez depender da lei. Esta é que ‘reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’ (art. 173, § 4.º)”.[69](#)

Em relação à previsão contida na CF/88, concordamos com José Afonso da Silva que a sua inserção entre os direitos fundamentais erigiu os consumidores à

categoria de **titulares de direitos constitucionais fundamentais**. Conjugando essa previsão à do art. 170, V, que eleva a **defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica**, “(...) tem-se o relevante efeito de legitimar todas as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção prevista. Isso naturalmente abre larga brecha na economia de mercado, que se esteia, em boa parte, na liberdade de consumo, que é a outra face da liberdade do tráfico mercantil fundada na pretensa lei da oferta e da procura (...)”. [70](#)

No tocante ao direito brasileiro, os conceitos gerais de **consumidor** e **fornecedor** e a noção de **produto** e **serviço**, atendendo aos preceitos constitucionais, foram regulados pelo **Código de Proteção e Defesa do Consumidor**, Lei n. 8.078, de 11.09.1990, inegável **microssistema** das **relações de consumo**. Excepcionalmente, contudo, desde que não haja conflito, havendo espaço, aplicar-se-ão as regras do Código Civil e de legislações extravagantes pertinentes à matéria.

O **atual Código Civil**, Lei n. 10.406, de 10.01.2002 (*DOU* de 11.01.2002), que entrou em vigor em **12.01.2003** (*vacatio legis* de 1 ano, de acordo com o seu art. 2.044), por seu turno, reafirmou a sua aplicação **subsidiária** no tocante às relações de consumo. Para se ter um exemplo, destacamos o art. 593: “a prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou **à lei especial** (no caso, exemplifique-se, o CDC), reger-se-á pelas disposições deste Capítulo”.

O art. 1.º do CDC estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de **ordem pública** e **interesse social**. Por consequência, conforme anotam Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “(...) o juiz deve apreciar de ofício qualquer questão relativa às relações de consumo, já que não incide nesta matéria o princípio dispositivo. Sobre elas não se opera a preclusão e as questões que delas surgem podem ser decididas e revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição”. [71](#)

Por fim, cabe referir que o **STF** decidiu que as **relações de consumo de natureza bancária** ou **financeira** estão protegidas pelo **Código de Defesa do Consumidor**. “Entendeu-se não haver conflito entre o regramento do sistema financeiro e a disciplina do consumo e da defesa do consumidor, haja vista que,

nos termos do disposto no art. 192 da CF, a exigência de lei complementar refere-se apenas à regulamentação da estrutura do sistema financeiro, **não abrangendo os encargos e as obrigações impostos pelo CDC às instituições financeiras, relativos à exploração das atividades dos agentes econômicos que a integram — operações bancárias e serviços bancários —, que podem ser definidos por lei ordinária**” (ADI 2.591/DF, Rel. orig. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 07.06.2006, *Inf. 430/STF*).

■ 14.10.20. Direito de petição e obtenção de certidões (art. 5.º, XXXIV)

Assegura-se a todos, independentemente do pagamento de taxas:

- o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- a **obtenção de certidões** em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Vislumbrado na Magna Carta de 1215, o **direito de petição** nasceu por meio do *right of petition*, na Inglaterra, consolidando-se no *Bill of Rights* de 1689. Consistia, nesse primeiro momento, no simples direito de o Grande Conselho, depois o Parlamento, pedir que o Rei sancionasse as leis. Fortaleceu-se na Constituição francesa de 1791 ao se ampliarem os peticionários e o objeto da petição.

Segundo José Afonso da Silva, “o direito de petição define-se ‘como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou situação’, seja para denunciar uma lesão concreta, e pedir a reorientação da situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade... Há, nele, uma dimensão coletiva consistente na busca ou defesa de direitos ou interesses gerais da coletividade”. [72](#)

Esse direito pode ser exercido por qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira e independe do pagamento de taxas.

Na Constituição anterior (1967 e EC n. 1/69) vinha atrelado ao *direito de representação*, que não mais se repete na de 1988. Parece-nos, no entanto, que o constituinte teve a intenção de unir os dois direitos, até porque a *representação* se manifesta por intermédio de uma *petição*.

Pode-se, então, afirmar estar ainda em vigor a Lei n. 4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade), que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, podendo a petição ser dirigida a qualquer autoridade do Executivo, Legislativo ou Judiciário.

Assim, o objetivo do direito de petição nada mais é que, em **nítido exercício das prerrogativas democráticas**, levar ao conhecimento do Poder Público a informação ou notícia de um ato ou fato ilegal, abusivo ou contra direitos, para que este tome as medidas necessárias.

Diferentemente do direito de ação, não tem o peticionário de demonstrar lesão ou ameaça de lesão a interesse, pessoal ou particular. Trata-se de nítida participação política por intermédio de um processo.

Embora a Constituição não fixe nenhuma sanção em caso de negativa ou omissão, parece-nos perfeitamente cabível a utilização do *mandado de segurança* para a obtenção de algum pronunciamento do Poder Público.

Enfim, **não** se pode confundir *direito de petição* com a necessidade de preenchimento da *capacidade postulatória* para a obtenção de pronunciamento judicial a respeito da pretensão formulada (salvo as exceções permitidas pelo ordenamento, como no *habeas corpus*), conforme muito bem vem destacando a jurisprudência do STF. Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello observa que “... ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do *jus postulandi*. A exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação jurídico-processual. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. O direito de petição qualifica-se como prerrogativa de extração

constitucional assegurada à generalidade das pessoas pela Carta Política (art. 5.º, XXXIV, ‘a’). Traduz direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado — que não dispõe de capacidade postulatória — ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros...” (AR 1.354 AgR/BA, *DJ* de 06.06.1997, p. 24873).

Em relação ao direito de **obtenção de certidões**, também independentemente do pagamento de taxa, o art. 1.º da Lei n. 9.051/95 dispõe que “as certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no **prazo** improrrogável de **quinze dias**, contado do registro do pedido no órgão expedidor”.

Parece razoável o art. 2.º da referida lei ao estabelecer que, “nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere esta lei, deverão os interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido”. Condenável, portanto, o pedido genérico de certidão, devendo o interessado discriminar o objeto de seu interesse.

Registrado o pedido de certidão, e não atendido de forma ilegal ou por abuso de poder, o remédio cabível será o **mandado de segurança**, e não o *habeas data*. Trata-se de direito líquido e certo de obter certidões expedidas pelas repartições públicas, seja para a defesa de direitos, seja para esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros. Como exemplo, o direito de o funcionário público obter certidão perante a autoridade administrativa para requerer a sua aposentadoria. Havendo negativa, o remédio cabível será o **mandado de segurança**, e não o *habeas data*.

Por fim, inegável que o direito de certidão não é absoluto, podendo ser negado em caso de o sigilo ser imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Nesse sentido, regulando o art. 23 da Lei n. 8.159/91, destaca-se o Decreto n. 7.845/2012.

■ 14.10.21. Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV)

O **princípio da inafastabilidade da jurisdição** é também nominado **direito de ação**, ou **princípio do livre acesso ao Judiciário**, ou, como assinalou Pontes de Miranda, **princípio da ubiquidade da Justiça**.

O inciso XXXV do art. 5.º da CF/88 estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Criticamos essa **forma indireta** de apresentação da garantia ao direito à jurisdição (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), que, provavelmente, foi adotada como reação a atos arbitrários que, aproveitando a inexistência de prescrição constitucional expressa (lembrar que referido direito só adquiriu o *status* de preceito constitucional com a Constituição de 1946), muitas vezes, por intermédio de lei ou decreto-lei, excluía da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito.

Muito melhor seria se referido princípio fosse prescrito na **forma direta**, como se verifica, dentre outras, nas Constituições da Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, na Declaração Universal dos Direitos Humanos etc.

Conforme já observamos, apesar dessa crítica terminológica, o inciso XXXV do art. 5.º da CF/88 veio sedimentar o entendimento amplo do termo “direito”, dizendo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a **direito**, não mais restringindo a sua amplitude, como faziam as Constituições anteriores, ao “direito individual” (*vide* arts. 141, § 4.º, da CF/46; 150, § 4.º, da Constituição de 1967; 153, § 4.º, da EC n. 1/69; 153, § 4.º, na redação determinada pela EC n. 7/77). A partir de 1988, passa a se assegurar, de forma expressa e categórica, em nível constitucional, a proteção de direitos, sejam eles **privados**, **públicos** ou **transindividuais** (difusos, coletivos ou individuais homogêneos). [73](#)

Prefere-se, ainda, seguindo a doutrina mais abalizada, a expressão “**acesso à ordem jurídica justa**” a “**acesso à Justiça**” ou “**ao Judiciário**”.

Isso porque, segundo a feliz distinção de Watanabe, “a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos

órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o *acesso à ordem jurídica justa*".⁷⁴

Nesse sentido, Cappelletti e Garth produziram interessante ensaio para o “Projeto de Florença”, ao qual já nos referimos nesta obra, identificando três grandes **ondas renovatórias** no processo evolutivo de **acesso à ordem jurídica justa**. A **primeira onda** teve início em 1965, concentrando-se na assistência judiciária.⁷⁵ A **segunda** referia-se às “... reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses ‘difusos’, especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor”. O **terceiro movimento ou onda** foi pelos autores chamado de “enfoque de acesso à justiça”, reproduzindo as experiências anteriores, mas indo além, buscando “... atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo”.⁷⁶

As expressões “lesão” e “ameaça a direito” garantem o livre acesso ao judiciário para postular tanto a tutela jurisdicional **preventiva** como a **repressiva**.

Apesar de ter por destinatário principal o legislador (que ao elaborar a lei não poderá criar mecanismos que impeçam ou dificultem o acesso ao judiciário), também se direciona a todos, de modo geral.

Não se confunde com o **direito de petição** (já visto no art. 5.º XXXIV, “a”), este um direito de **participação política**, não sendo necessário demonstrar qualquer interesse processual ou lesão a direito pessoal. “Enquanto o direito de ação é um direito público subjetivo, pessoal, portanto, salvo nos casos dos direitos difusos e coletivos, onde os titulares são indetermináveis e indeterminados, respectivamente, o direito de petição, por ser político, é impessoal, porque dirigido à autoridade para noticiar a existência de ilegalidade ou abuso de poder, solicitando as providências cabíveis”.⁷⁷

Em decorrência do princípio em análise, **não** mais se admite no sistema constitucional pátrio a chamada **jurisdição condicionada** ou **instância administrativa de curso forçado**, tal como se verificava no art. 153, § 4.º, da EC n. 1/69, na redação dada pela EC n. 7, de 13.04.1977.⁷⁸ Para ingressar

(“bater às portas”) no poder judiciário não é necessário, portanto, o prévio esgotamento das vias administrativas.

Exceção a essa regra, a esse direito e garantia individual (cláusula pétrea), só admissível se introduzida pelo poder constituinte originário, como acontece com a **Justiça desportiva** (art. 217, §§ 1.º e 2.º).⁷⁹

Como veremos ao estudar o **habeas data**, situação semelhante também foi prevista pela Lei n. 9.507/97. Remetemos o leitor para o referido estudo (*item 14.11.6* deste capítulo), onde expomos nosso entendimento sobre esse ponto específico da matéria.

Também destacamos o art. 7.º, § 1.º, da Lei n. 11.417/2006 (**súmula vinculante**) ao estabelecer que “contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas”.

Trata-se, conforme anotamos no *item 11.14.11.9*, de instituição, por parte da lei, de *contencioso administrativo atenuado* e sem violar o princípio do livre acesso ao Judiciário (art. 5.º, XXXV), na medida em que o que se veda é somente o ajuizamento da reclamação, e não de qualquer outra medida cabível, como a ação ordinária, o mandado de segurança etc.

Outro tema interessante já enfrentado pelo STF diz respeito à exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, a fim de que se postule judicialmente a **concessão de benefício previdenciário**.

Em razão da definição de parâmetros muito particulares, pedimos vênias para esquematizar as principais regras definidas pela Corte no julgamento do **RE 631.240** (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014, *DJE* de 10.11.2014):

■ “a instituição de **condições** para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5.º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de **interesse em agir**, é preciso haver **necessidade de ir a juízo**. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para

sua análise”;

■ essa exigência de **prévio requerimento administrativo** “não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado”, bem como nas hipóteses de “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível”, podendo, então, “o pedido ser formulado diretamente em juízo — salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”.

Em razão da prolongada oscilação da jurisprudência sobre o assunto, o STF estabeleceu uma **fórmula de transição** para as ações em curso e ajuizadas até a conclusão do referido julgamento (03.09.2014):

■ “(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

■ (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”.

Não sendo o caso das hipóteses estabelecidas acima, o STF determinou o **sobrestamento** das ações para as seguintes **providências**:

■ “o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo”;

■ “comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão”;

■ “se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir”.

Por fim, a permissibilidade conferida pela **Lei n. 9.307/96** (Lei da Arbitragem), com as profundas **ampliações** introduzidas pela **Lei n.**

13.129/2015, para as pessoas capazes de contratar valerem-se da **arbitragem (de direito ou de equidade)** para dirimir litígios relativos a **direitos patrimoniais disponíveis**.

A citada Lei n. 13.129/2015, apesar de existirem algumas poucas leis esparsas e pontuais sobre o tema, consolidou, de modo bastante avançado, a possibilidade de a **administração pública direta e indireta** utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais **disponíveis**. A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a que teria a atribuição para a realização de acordos ou transações. Em atenção ao art. 37, *caput*, CF/88 (princípio da legalidade), a arbitragem que envolva a administração pública será sempre **de direito** e respeitará o princípio da publicidade.

Submetendo a solução do litígio a juízo arbitral, mediante **convenção de arbitragem**, assim entendida a *cláusula compromissória* e o *compromisso arbitral*, não se abre mão do direito de ação; apenas se autoriza a opção por uma **jurisdição privada**.

“O que não se pode tolerar por flagrante inconstitucionalidade é a exclusão, pela lei, da apreciação de lesão a direito pelo Poder Judiciário, que não é o caso do juízo arbitral. O que se exclui pelo compromisso arbitral é o acesso à via judicial, mas não à jurisdição. Não se poderá ir à justiça estatal, mas a lide será resolvida pela justiça arbitral. Em ambas há, por óbvio, a atividade jurisdicional”. [80](#)

Lembrar que a arbitragem não é obrigatória, mas facultativa (fica a cargo das partes escolher quem deve solucionar a lide — juiz estatal ou privado), e, mesmo havendo a sua escolha, o art. 32 da Lei n. 9.307/96 admite seja **declarada a nulidade da sentença arbitral** por decisão do **Judiciário** nos casos previstos na lei.

■ 14.10.22. Limites à retroatividade da lei (art. 5.º, XXXVI)

Como regra, conferindo **estabilidade às relações jurídicas**, o constituinte

originário dispôs que a lei não prejudicará o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada**.⁸¹

O art. 6.º da *LINDB — Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro* (Decreto-lei n. 4.657/42) assim define os institutos:

■ **direito adquirido**: direito que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem;

■ **ato jurídico perfeito**: ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou;

■ **coisa julgada**: decisão judicial de que não caiba mais recurso.

No tocante ao **direito adquirido**, como já comentamos ao tratar da teoria do poder constituinte, não se poderá alegá-lo em face da manifestação do poder constituinte originário, uma vez que este é incondicionado e ilimitado juridicamente. No entanto, em se tratando de manifestação do poder constituinte derivado reformador, em virtude do limite material da cláusula pétrea prevista no art. 60, § 4.º, IV, entendemos que os direitos adquiridos deverão ser preservados.⁸² Não se pode confundir “direito adquirido” com mera “expectativa de direito”. Celso de Mello fala, de maneira interessante, em **“ciclos de formação”**: “a questão pertinente ao reconhecimento, ou não, da consolidação de situações jurídicas definitivas há de ser examinada em face dos ciclos de formação a que esteja eventualmente sujeito o processo de aquisição de determinado direito. Isso significa que a superveniência de ato legislativo, em tempo oportuno — vale dizer, enquanto ainda não concluído o ciclo de formação e constituição do direito vindicado — constitui fator capaz de impedir que se complete, legitimamente, o próprio processo de aquisição do direito (*RTJ* 134/1112 — *RTJ* 153/82 — *RTJ* 155/621 — *RTJ* 162/442, v.g.), inviabilizando, desse modo, ante a existência de mera ‘spes juris’, a possibilidade de útil invocação da cláusula pertinente ao direito adquirido” (**RE 322.348-AgR/SC**, Rel. Min. Celso de Mello).

Nesse sentido, em várias oportunidades, consolidou-se a jurisprudência do

STF pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico instituído por lei para os funcionários públicos (ADI 255/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* de 02.05.2003; RE 368.715/MS — AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* de 22.08.2003; RE 340.896/SC, Moreira Alves, *DJ* de 19.12.2002; RE 346.655/PR, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 08.11.2002).

O STF entendeu perfeitamente possível que a lei traga novas regras e preserve a mera expectativa de direito em benefício de cidadãos, por exemplo, o parágrafo único do art. 1.º da Lei estadual n. 200/74 (SP), que, ao revogar a legislação que concedia benefício de complementação de aposentadoria, ressalvou os direitos dos empregados admitidos até a data de sua vigência. Nesse sentido, a **S. 654/STF**: “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5.º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado”.

Lembramos, ainda, no tocante ao direito penal, do **princípio da retroatividade da lei mais benéfica**, previsto no art. 5.º, XL, da CF.

No que tange ao **ato jurídico perfeito**, destacamos a **Súmula Vinculante 1**: “ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, **sem ponderar as circunstâncias do caso concreto**, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar n. 110/2001” (30.05.2007).

Assim, os acordos feitos com base na LC n. 110/2001 estão mantidos (tendo em vista o princípio constitucional do ato jurídico perfeito), não se podendo presumir, para todos os casos, aplicando-se regra em abstrato, que tenha havido vício de consentimento em algum dos elementos formadores da vontade do trabalhador comum ao assinar o acordo com a CEF em relação aos expurgos inflacionários do FGTS. [83](#)

Finalmente (cf. *item 6.7.1.17.4.2*), analisando o instituto da coisa julgada, em **situação excepcionalíssima**, o STF afastou a alegação de segurança jurídica (coisa julgada) para fazer valer o *direito fundamental de que toda pessoa tem de conhecer as suas origens* (**princípio da busca da identidade genética**), especialmente se, à época da decisão que se procura rescindir, não se pôde fazer

o exame de DNA.

A decisão foi tomada, em **02.06.2011**, por **7 x 2**, no julgamento do **RE 363.889**, concedendo à recorrente o direito de, depois de mais de 10 anos, voltar a pleitear, perante o suposto pai, a realização do **exame de DNA**, tendo em vista que, na primeira decisão, muito embora beneficiária da assistência judiciária, a recorrente não podia arcar com as custas para a sua realização.

■ 14.10.23. Princípio do promotor natural (art. 5.º, LIII)

Já foi visto neste estudo que o acusado tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, **vedando-se**, por consequência, a **designação arbitrária**, inclusive, de **promotores ad hoc** ou **por encomenda** (art. 5.º, LIII, e art. 129, I, c/c o art. 129, § 2.º).

O STF aceitou a ideia de *promotor natural* no julgamento do **HC 67.759** (*leading case*).

Para aprofundamento, remetemos o nosso querido leitor para o *item 12.2.6* da presente obra.

■ 14.10.24. Princípio do juiz natural ou legal (art. 5.º, XXXVII e LIII)

A Constituição estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção, não podendo ninguém ser processado nem **sentenciado** *senão* pela **autoridade competente**.

Segundo a doutrina, “o conteúdo jurídico do princípio pode ser resumido na inarredável necessidade de **predeterminação do juízo competente**, quer para o processo, quer para o julgamento, proibindo-se qualquer forma de designação de tribunais para casos determinados. Na verdade, o princípio em estudo é um **desdobramento** da regra da **igualdade**. Nesse sentido Pontes de Miranda aponta que a ‘proibição dos tribunais de exceção representa, no direito constitucional contemporâneo, *garantia constitucional*: é direito ao juízo legal

comum’, indicando vedação à discriminação de pessoas ou casos para efeito de submissão a juízo ou tribunal que não o recorrente por todos os indivíduos”. [84](#)

Nery, em interessante estudo, caracteriza a garantia do juiz natural como **tridimensional**:

- “não haverá juízo ou tribunal *ad hoc*, isto é, tribunal de exceção;
- todos têm o direito de submeter-se a julgamento (civil ou penal) por juiz competente, pré-constituído na forma da lei;
- o juiz competente tem de ser imparcial”. [85](#)

Assim, o que se veda é a designação ou criação, por deliberação legislativa ou outra, de tribunal (de exceção) para julgar, através de processo (civil, penal ou administrativo), determinado caso, tenha ele já ocorrido ou não, irrelevante a já existência de tribunal, [86](#) não abrangendo na aludida proibição a **Justiça especializada**, nem tampouco **tribunais de ética**, como o da OAB, cujas decisões administrativas (disciplinares) poderão ser revistas pelo Judiciário.

Acrescentamos, ainda, que a **prerrogativa de foro** não afronta o princípio do juiz natural ou legal (*gesetzlicher Richter*). No mesmo sentido, nas hipóteses de competência relativa, por convenção das partes e dentro dos limites legais, não há nenhuma vedação em relação aos **foros de eleição**. Conforme vimos (*item 14.10.21*), também não se caracteriza nenhuma violação ao princípio do juiz natural a instituição do **juízo arbitral**.

Outro ponto bastante polêmico, especialmente depois de terem sido fixadas *metas* de julgamento em razão da *Reforma do Judiciário*, tem sido a convocação de juízes de primeiro grau para atuar em Tribunal.

A argumentação de afronta ao **princípio do juiz natural** é bem razoável e consistente (cf. arts. 93, III, 94 e 98, I), mas o STF, diante da ideia de *efetividade e celeridade processual* (art. 5.º, LXXVIII), nessa ponderação de valores, vem fazendo prestigiar a agilidade, até porque, segundo analisado, as convocações estão sendo feitas com base em lei (cf. *item 11.9 e Inf. 581/STF — HC 96.821*, Rel. Min. Lewandowski, j. 08.04.2010, Plenário, *DJE* de 25.06.2010).

Com o justo objetivo de garantir a segurança dos magistrados, resta alertar sobre a inconveniência e inconstitucionalidade de adoção da figura do “**juiz sem rosto**”, motivada, à época da discussão, pela onda de violência e assassinatos de juízes das execuções criminais de São Paulo e Espírito Santo, defendendo a omissão dos nomes dos juízes durante a tramitação do processo e na sentença.

Com todo o respeito, a figura do “juiz sem rosto” implica incontestemente afronta à garantia do juiz natural, direito fundamental consagrado no Estado Democrático de Direito.^{[87](#)}

Por fim, destacamos a importante novidade introduzida pela **EC n. 45/2004** ao estabelecer que “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão” (art. 5.º, § 4.º).

A nova regra, sem dúvida, surge em total consonância e em fortalecimento ao **princípio do juiz natural**.

Consoante assinalou Luiz Flávio Gomes, “o TPI terá uma grande vantagem em relação aos atuais Tribunais (*ad hoc*) criados pelo Conselho de Segurança da ONU, que é constituído de quinze membros (15 países, dos 189 que a integram). Terá legitimidade, força moral e poder jurídico, o que não ocorre hoje com os Tribunais em funcionamento que estão julgando os crimes ocorridos na antiga Iugoslávia, Ruanda etc. Esses Tribunais satisfazem o senso de justiça, sinalizam oposição clara às arbitrariedades e atrocidades cometidas em praticamente todo o planeta, porém, não são Cortes predeterminadas em lei nem constituídas previamente (viola-se, assim, o princípio do juiz natural). A criação do TPI, dessa forma, significa respeito à garantia do princípio do juiz natural, que possui duas dimensões: *a*) juiz previamente previsto em lei ou Constituição (juiz competente); *b*) proibição de juízos ou tribunais de exceção, isto é, *ad hoc* (cfr. CF, art. 5.º, XXXVII e LIII)”.^{[88](#)}

■ 14.10.25. Tribunal Penal Internacional — “TPI” (art. 5.º, § 4.º — EC n. 45/2004)

Como acabamos de assinalar, a **Reforma do Judiciário** estabeleceu a

submissão do Brasil à jurisdição do **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha **manifestado adesão**.[89](#)

Já dispunha o art. 7.º do ADCT da CF/88 que o Brasil lutaria em defesa da formação de um **tribunal internacional dos direitos humanos**.

O **Estatuto de Roma**, que cria o **Tribunal Penal Internacional**, foi aprovado em 17.07.1998. O Brasil assinou o aludido estatuto em 07.02.2000 e o Congresso Nacional o aprovou, por meio do Decreto Legislativo n. 112, em 06.06.2002, promulgado, em 26.09.2002, pelo Decreto presidencial n. 4.388. A *carta de ratificação* fora depositada em 20.06.2002, entrando em vigor em 1.º.07.2002. Para o Brasil, internacionalmente (art. 126), passou a vigorar em 1.º de setembro de 2002.

O “TPI” será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional (fixados nos termos do Estatuto), e será **complementar** às jurisdições penais nacionais (art. 1.º do Estatuto).

Consagra-se, dessa forma, o **princípio da complementaridade**, preservando-se o sistema jurídico interno, na medida em que o “TPI” só exercerá jurisdição em caso de incapacidade ou omissão dos Estados.

Em respeito à soberania nacional (art. 1.º, I), há sérias dúvidas sobre a aplicação, por exemplo, do art. 77, 1, “b”, do Estatuto, que prevê a *prisão perpétua*, em contraposição ao art. 5.º, XLVII, “b”, da CF/88. Se nem mesmo por *emenda constitucional* se poderia instituir a pena de caráter perpétuo (art. 60, § 4.º, IV), o que dizer por tratado sobre direitos humanos que terá, no máximo, a teor do art. 5.º, § 3.º, equivalência às emendas se aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros?[90](#)

Outros vários pontos polêmicos precisam ser resolvidos pelo STF, como a previsão de reexame de questões já decididas pelo TPI (art. 17 do *Estatuto de Roma*), em afronta à coisa julgada, direito fundamental previsto na CF/88.

Outrossim, a distinção que deve ser feita entre **extradição** e **entrega** (*surrender*) ao TPI.

Em nosso entender, existiriam, basicamente, 3 jurisdições: **a)** a **brasileira**, cujos órgãos estão previstos no art. 92; **b)** a do **TPI** em relação à qual o Brasil a ela se submete; e **c)** a de **Tribunais estrangeiros**, cujas decisões deverão passar por um processo de homologação da sentença, já que estrangeira, e concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.

Esse processo de homologação não deverá ser observado em relação às decisões do TPI, porque o Brasil a elas se submete. Ainda, a entrega de brasileiro ou estrangeiro para o TPI não seguirá o mesmo procedimento da extradição, pois a **entrega** será para julgamento em Tribunal a cuja jurisdição o Brasil se submete.

Contudo, alguns limites deverão existir, como a questão da comutação da pena, não se admitindo, por exemplo, a prisão perpétua etc., tema a ser resolvido pelo STF na **Pet. 4.625**, interposta pelo TPI em 16.07.2009, e que requer a eventual prisão e **entrega** do Presidente do Sudão, caso ele entre no território brasileiro, acusado de ter *cometido crimes contra a humanidade* e de *guerra*.⁹¹

De acordo com o art. 3.º do Estatuto, o Tribunal tem sede em *Haia*, Países Baixos (“o Estado anfitrião”), podendo funcionar em outro local sempre que se entender conveniente e nos termos do Estatuto.

O art. 86 consagra o **princípio da cooperação** na medida em que os Estados-partes deverão **cooperar** plenamente com o Tribunal no inquérito e no procedimento contra crimes da competência deste.

Por fim, cabe destacar que a competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves que afetem a comunidade internacional no seu conjunto.

O art. 5.º do Estatuto estabelece que o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes:

- de genocídio;
- contra a humanidade;
- de guerra;
- de agressão.

O tema deverá ser aprofundado em compêndios de direitos humanos e em obras de direito penal e processual penal, imaginando os questionamentos nos concursos estarem mais nessas áreas do que na constitucional!

■ **14.10.26. Federalização dos crimes contra direitos humanos (art. 109, V-A e § 5.º — EC n. 45/2004) — Incidente de deslocamento de competência — IDC**

Como sabemos, a **dignidade da pessoa humana** é **fundamento** da República Federativa do Brasil (art. 1.º, III), que, em suas relações internacionais, rege-se, dentre outros, pelos princípios **da prevalência dos direitos humanos**, do **repúdio ao terrorismo** e ao **racismo** e pela **cooperação entre os povos para o progresso da humanidade** (art. 4.º, II, VIII e IX).

Os **direitos da pessoa humana**, nos termos do art. 34, VII, “b”, foram erigidos a **princípios sensíveis**, a ensejar até mesmo a intervenção federal nos Estados que os estiverem violando.

Outrossim, nos termos do art. 21, I, a União é que se responsabiliza, em nome da República Federativa do Brasil, pelas regras e preceitos fixados nos tratados internacionais. Assim, na hipótese de descumprimento e afronta a direitos humanos no território brasileiro, a única e exclusiva responsável, no plano internacional, será a União, não podendo invocar a cláusula federativa, nem mesmo “lavar as mãos” dizendo ser problema do Estado ou do Município. Isso não é aceito no âmbito internacional.

Acontece que, na maioria dos casos, antes da **Reforma do Judiciário**, a União não tinha competência para apurar, processar e julgar tais crimes.

Essa problemática foi muito bem apontada pela *Associação Nacional dos Procuradores da República — ANPR*, que apresentou importantes sugestões aos membros da Comissão de Reforma, após avaliar o relatório do Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

Conforme sugerido pela *ANPR*, “... é a União, na qualidade de ente federado com personalidade jurídica na esfera internacional, que tem o poder de contrair

obrigações jurídicas internacionais em matéria de direitos humanos, mediante a ratificação de tratados. Consequentemente, a sistemática de monitoramento e fiscalização de tais obrigações recai na pessoa jurídica da União. Deste modo, por coerência, há de caber à União a responsabilidade para apurar, processar e julgar casos de violação de direitos humanos, uma vez que, por comandos internacionais, obrigou-se a fazer valerem tais direitos em todo o território nacional. Daí a imperiosidade de se atribuir à Justiça Federal competência para o julgamento das violações mais sérias aos direitos humanos”.[92](#)

Adequando o funcionamento do Judiciário brasileiro ao sistema de proteção internacional dos direitos humanos, a **EC n. 45/2004** fez a seguinte previsão:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

V-A — as **causas relativas a direitos humanos** a que se refere o § 5.º deste artigo;

(...)

§ 5.º Nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos**, o **Procurador-Geral da República**, com a finalidade de **assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte**, poderá suscitar, perante o **Superior Tribunal de Justiça**, em qualquer fase do inquérito ou processo, **incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal**” (original sem grifos).

Segundo o **STJ** (na decisão proferida no IDC 2), o deslocamento da competência do juízo estadual para o federal vai depender do preenchimento dos seguintes **pressupostos**:

- existência de grave violação a direitos humanos;
- risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais;
- incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas.

Ainda, conforme ficou anotado na ementa do acórdão do IDC 5, “o incidente

de deslocamento de competência não pode ter o caráter de *prima ratio*, de primeira providência a ser tomada em relação a um fato (por mais grave que seja). Deve ser utilizado em **situações excepcionálíssimas**, em que efetivamente demonstrada a sua necessidade e a sua imprescindibilidade, ante provas que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade política, falta de condições pessoais e/ou materiais das instituições — ou de uma ou outra delas — responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação a direito humano, em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na conduta criminosa, até para não se esvaziar a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal”.

Dessa forma, a fixação da competência da Justiça Federal parece-nos muito bem-vinda e acertada. O grande problema está no procedimento de deslocamento de competência da Justiça Estadual (ou Distrital) para a Federal.

Perceba-se que isso acontecerá somente se o **PGR**, e exclusivamente ele, conseguir demonstrar que no âmbito Estadual ou Distrital está havendo *descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte* e, por consequência, *grave violação de direitos humanos*. Mas o que é grave violação de direitos humanos? E mais, sabendo que se trata de incidente de deslocamento de competência, nitidamente será fixado o Tribunal após a ocorrência do fato, em desrespeito ao princípio do juiz natural, já estudado (art. 5.º, XXXVII e LIII).

Nesse sentido, uma outra redação, vaga e indeterminada, ainda em tramitação na Câmara (que pode ser aqui aproveitada), já tinha sido objeto de críticas do *Deputado Jarbas Lima*: “a norma proposta rompe, nesse passo, com a melhor tradição democrática de nossas cartas constitucionais, cria insegurança jurídica e, o que é mais grave, consagra juízos de exceção na medida em que atribui a determinada autoridade ou órgão, de forma discricionária, a escolha do juízo ou tribunal para, caso a caso, julgar um ou mais processos dados”.⁹³

No Relatório já citado, a ANPR assim se manifestou: “tal indeterminação de critérios para o deslocamento de competência, e, no mínimo, as candentes dúvidas quanto à constitucionalidade da proposta (à luz dos incs. XXXVII e LIII

do art. 5.º, CF, c/c o art. 60, § 4.º, IV) trazem a probabilidade de que, se aprovada tal proposta, a CF será, no tocante a essa matéria, alterada inocuamente, perdendo-se uma oportunidade ímpar de o Brasil adotar uma solução mais efetiva para o gravíssimo quadro de desrespeito sistemático aos direitos humanos”.[94](#)

Em referido relatório, levando em consideração as diversas convenções sobre direitos humanos de que o País já é parte, destacando, ainda, o reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos,[95](#) a aludida Associação chegou a propor uma nova redação, definindo, previamente, o que entenderia por hipóteses de **grave violação de direitos humanos** e, também, permitindo que a lei ordinária, no futuro, em face de novas convenções que viessem a ser celebradas, estabelecesse outras hipóteses de crimes contra direitos humanos. Haveria, dessa forma, total respeito ao juiz natural.

Apenas para exemplificar, o que poderá servir de norte para a interpretação dos estudiosos, foram considerados, pela ANPR, crimes contra direitos humanos os seguintes delitos:

- tortura;
- homicídio doloso praticado por agente de quaisquer dos entes federados no exercício de suas funções ou por grupo de extermínio;
- crimes praticados contra as comunidades indígenas ou seus integrantes;
- homicídio doloso, quando motivado por preconceito de origem, raça, sexo, opção sexual, cor, religião, opinião política, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, ou quando decorrente de conflitos fundiários de natureza coletiva;
- uso, intermediação e exploração de trabalho escravo ou de crianças e adolescentes, em quaisquer das formas previstas em tratados internacionais.

Tirando todos esses detalhes e desde que o STF não conteste a constitucionalidade da nova regra, concordamos inteiramente com Piovesan nos seguintes termos: “para os Estados, ao revés, cujas instituições mostrarem-se

falhas ou omissas, restará configurada a hipótese de deslocamento de competência para a esfera federal, o que:

- a) **assegurará maior proteção à vítima;**
- b) **estimulará melhor funcionamento das instituições locais** em casos futuros;
- c) gerará a expectativa de **resposta efetiva das instituições federais;**
- d) se ambas as instituições — estadual/federal — mostrarem-se falhas ou omissas, daí, sim, será **acionável a esfera internacional** — contudo, com a possibilidade de, ao menos, dar-se a chance à União de responder ao conflito, esgotando-se a responsabilidade primária do Estado (o que ensejaria a responsabilidade subsidiária da comunidade internacional). Isto equacionará, ademais, a posição da União no contexto de responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos”.[96](#)

Finalmente, informamos (até o fechamento desta edição), os julgamentos dos IDCs ns. 1 (*negado*), 2 (*acolhido*), 3 (*acolhido em parte*) e 5 (*acolhido*):

■ **IDC 1/PA — assassinato de Dorothy Stang:** superando a preliminar que discutia a constitucionalidade da nova regra, a 3.^a Seção do STJ “... indeferiu o pedido no incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal do processo e julgamento do crime de assassinato da religiosa *Irmã Dorothy Stang*, ocorrido em Anapu-PA, por considerar descabível a advocatória ante a **equivocada** presunção vinculada, mormente pela mídia, de haver, por parte dos órgãos institucionais da segurança e judiciário do Estado do Pará, **omissão** ou **inércia** na condução das investigações do crime e sua efetiva punição pela grave violação dos direitos humanos, em prejuízo ao princípio da autonomia federativa (EC n. 45/2004)” (3.^a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 08.06.2005, *DJ* de 10.10.2005);

■ **IDC 2/DF — assassinato de Manoel Bezerra de Mattos Neto:** “... o advogado e vereador pernambucano Manoel Bezerra de Mattos Neto foi assassinado em 24.01.2009, no Município de Pitimbu/PB, depois de sofrer

diversas ameaças e vários atentados, em decorrência, ao que tudo leva a crer, de sua **persistente e conhecida atuação contra grupos de extermínio** que agem impunes há mais de uma década na divisa dos Estados da Paraíba e de Pernambuco, entre os Municípios de Pedras de Fogo e Itambé”. No caso concreto, o STJ entendeu preenchidos os requisitos para o deslocamento, especialmente a omissão e “incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas”. Assim, determinou o **deslocamento** de competência para **a Justiça Federal** no Estado da Paraíba, devendo a ação ser distribuída ao Juízo Federal Criminal com jurisdição no local do fato principal (3.^a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.10.2010 — *DJe* de 22.11.2010);

■ **IDC 3/GO — suspeita de atuação, em Goiânia, de grupo de extermínio com a suposta participação de policiais militares na prática dos crimes de homicídio e de tortura:** o STJ determinou o deslocamento de competência para a Justiça Federal de dois inquéritos policiais e de um procedimento inquisitivo envolvendo policiais militares que teriam supostamente cometido graves violações aos direitos humanos no estado de Goiás. Assim, “o Colegiado determinou a transferência imediata à Polícia Federal, sob a fiscalização do Ministério Público Federal e sob a jurisdição do juízo federal criminal, do inquérito policial envolvendo o desaparecimento de Célio Roberto; do procedimento inquisitivo que trata do crime de tortura contra Michel Rodrigues da Silva; e do inquérito policial que apura o desaparecimento de Pedro Nunes da Silva e Cleiton Rodrigues” (*Notícias STJ de 10.12.2014*) (3.^a Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.12.2014, *DJE* de 02.02.2015);

■ **IDC 5/PE — morte do promotor Thiago Faria Soares:** de acordo com os itens 8 e 9 da ementa, há “indicativos de que o assassinato provavelmente resultou da ação de grupos de extermínio que atuam no interior do Estado de Pernambuco (como tantos outros que ocorreram na região conhecida como ‘Triângulo da Pistolagem’, situada no agreste pernambucano), bem como ao certo e notório conflito institucional que se instalou, inarredavelmente, entre

os órgãos envolvidos com a investigação e a persecução penal dos ainda não identificados autores do crime noticiado. A falta de entendimento operacional entre a Polícia Civil e o Ministério Público estadual ensejou um conjunto de falhas na investigação criminal que arrisca comprometer o resultado final da persecução penal, com possibilidade, inclusive, de gerar a impunidade dos mandantes e dos executores do citado crime de homicídio” (3.^a Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.08.2014, *DJE* de 1.^o.09.2014).

■ 14.10.27. Tribunal do Júri (art. 5.^o, XXXVIII)

A CF/88 reconhece a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurando: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Essa regra de **competência**, contudo, **não é absoluta**. Isso porque, sempre que houver instituição de competência especial por prerrogativa de função no texto maior (CF/88), haverá afastamento da norma geral. É o que acontece nos arts. 29, X (Prefeito julgado pelo TJ); 96, III (Juízes e Promotores — TJ); 102, I, “b” e “c” (o crime comum engloba o crime doloso contra a vida); 105, I, “a”, e 108, I.

Fazemos, então, amigo, “guerreiro” que se prepara para os “concursos da vida”, uma pergunta: será que a Constituição de um Estado pode retirar competência do Tribunal do Júri na hipótese de prática de crime doloso contra a vida fora das exceções previstas na própria CF? Ou seja, será que a Constituição de um Estado pode atribuir, por exemplo, competência para o TJ julgar Vereador pela prática de crime doloso contra a vida (homicídio), sabendo que a CF não traz essa exceção à regra geral do art. 5.^o, XXXVIII? A resposta é negativa, e o STF já pacificou o entendimento no enunciado da **S. 721**, convertida na **SV 45** (j. 08.04.2015), nos seguintes termos: “a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual”.

Caso o crime doloso contra a vida tenha sido praticado em coautoria, tendo um dos réus foro por prerrogativa de função e o outro não, haverá separação dos processos; aquele que não tem a prerrogativa, certamente, deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri.

■ 14.10.28. Segurança jurídica em matéria criminal (art. 5.º, XXXIX a LXVII) e a teoria dos mandados expressos de criminalização à luz dos direitos fundamentais

Nesta parte do trabalho limitamo-nos a transcrever os direitos previstos, de maneira sistematizada, na medida em que o questionamento, em maior profundidade, aparece nas provas de **direito penal** e **direito processual penal**; remetemos, pois, os candidatos para os livros especializados nesses assuntos.

No tocante à matéria criminal, destacamos a importante criação, no âmbito do STF, de um **Núcleo de Acompanhamento de Ações Penais originárias**.

Segundo Gilmar Mendes, a ideia “... é exatamente evitar que exista demora na tramitação dos processos, principalmente nas fases em que são ‘utilizados’ juízes federais para auxiliar na instrução do processo, ouvindo réus e testemunhas. A ação penal do **mensalão** foi um exemplo disso, salientou. Houve um acompanhamento rigoroso, e os interrogatórios acabaram acontecendo de forma bastante célere, lembrou” (*Notícias STF*, 1.º.07.2008 — 17h40).

Nessa linha, *Luiz Carlos dos Santos Gonçalves* procura, em vez de caminhar para uma proposta muitas vezes de abolição penal e que poderíamos chamar de **direito penal mínimo**, ou, no extremo oposto, acolher a ideia de um **direito penal máximo**, o faz dentro de uma perspectiva moderna e “antenado” com a ideia de uma **Constituição Social**, desenvolvendo a tendência para o **direito penal proporcional**.

Em suas conclusões, observa o autor que “entre os desafios para a implementação dos direitos fundamentais encontra-se o **uso proporcional do Direito Penal**: de adversárias daqueles direitos, viram-se as sanções penais alçadas a instrumento necessário para sua proteção. Esta transposição não foi

retilínea, nem está acabada. A busca por um Direito Penal Proporcional, que não descure das garantias fundamentais das pessoas investigadas, acusadas e sancionadas, nem deixe à míngua vítimas de graves ofensas a direitos, é incessante. O caminho que se apresenta para este fim é o da exegese constitucional, de onde se pode haurir a normativa que há de dirigir a atuação do Estado”.[97](#)

■ 14.10.28.1. Legalidade e anterioridade da lei penal incriminadora. Irretroatividade da lei penal “*in pejus*” (art. 5.º, XXXIX e XL)

O art. 5.º, XXXIX, consagra a regra do *nullum crimen nulla poena sine praevia lege*. Assim, de uma só vez, assegura tanto o **princípio da legalidade** (ou reserva legal), na medida em que não há crime sem **lei** que o defina, nem pena sem cominação **legal**, como o **princípio da anterioridade**, visto que não há crime sem lei **anterior** que o defina, nem pena sem **prévia** cominação legal.

Por sua vez, a regra do inciso XL do art. 5.º consagra, duplamente, a:

■ **irretroatividade da lei penal *in pejus***;

■ **retroatividade da lei penal mais benéfica.**

A) Irretroatividade da lei penal *in pejus*

Para se ter um **exemplo** importante da regra da irretroatividade da lei penal menos benéfica, o STF discutia a constitucionalidade do art. 2.º da Lei de Crimes Hediondos que **determinava** o cumprimento da pena **integralmente** no *regime fechado*.

Em um caso concreto (**HC 82.959**), entendeu que a proibição da progressão violaria o princípio da **individualização da pena**, garantido no art. 5.º, XLVI.

O STF passou, então, a **admitir a progressão**, aplicando a Lei de Execuções Penais, desde que, entre outros requisitos, fosse cumprido pelo menos **1/6** da pena (“até que **norma legal específica** venha a ser editada. Norma que, agora sim, cuide de forma **particularizada** o tema da progressão no regime de cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Isto, lógico, desde que

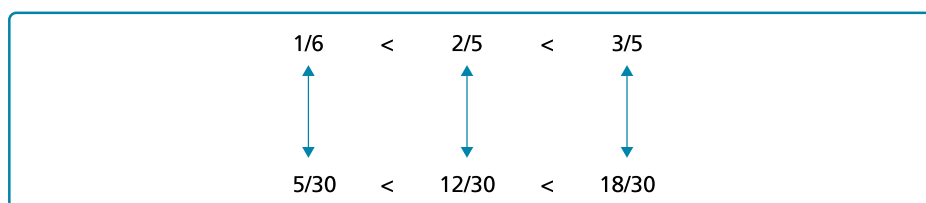
também sejam preenchidos os requisitos subjetivos que a própria lei já estabelece, o que será analisado, *in concreto*, pelo Juízo da execução” — voto do Min. Carlos Britto, fls. 712 do acórdão).

Posteriormente, a **Lei n. 11.464/2007**, norma legal específica, alterou o art. 2.º da Lei de Crimes Hediondos e passou a exigir o requisito temporal de **2/5**, se **primário** ou **3/5**, se **reincidente**.

A dúvida consistia em saber se deveria ser aplicada a Lei de Crimes Hediondos (1/6) ou a *novatio legis* (2/5, se primário ou 3/5, se reincidente). A resposta vai depender do momento em que o crime foi praticado e se já vigorava ou não a nova lei. Assim, se o crime foi praticado antes da Lei n. 11.464/2007, aplica-se 1/6, já que a *novatio legis* se implementou *in pejus*. Se, porém, o crime foi praticado já na vigência da nova lei, aplica-se 2/5 ou 3/5.

Isso porque, 1/6 é menor que 2/5, que é menor que 3/5 e, então, a nova lei sobreveio de forma menos benéfica (como se percebe, trata-se de tese interessante a ser adotada nas provas da **defensoria pública**).

Apenas para compreender bem a análise “matemática” (e aqui eu falo com os ilustres leitores que não gostam muito das “exatas” — porque sei que engenheiros, contadores e tantos “guerreiros” das áreas “não jurídicas” estão lendo o trabalho — o que muito me honra), vou socorrer-me do “MMC” e, assim, comparar as frações sob um múltiplo comum. Vejamos:



Destacamos a **SV 26/2009**, transcrita abaixo e que passa a ser um interessante exemplo prático para a aplicação do **princípio da irretroatividade da lei menos benéfica**:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a **inconstitucionalidade** do art. 2.º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o

condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Cabe lembrar que o entendimento acima exposto está consagrado na **S. 471/STJ**: “os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos **antes** da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”, bem como em diversos precedentes do STF, como no RE 579.167/AC (j. 16.05.2013).

Finalmente, apenas a título de informação (o tema é aprofundado em direito penal), devemos alertar que o STF declarou, incidentalmente, com efeito *ex nunc*, a inconstitucionalidade da regra fixada pela Lei n. 11.464/2007 ao art. 2.º, § 1.º, da Lei de Crimes Hediondos.

Vamos lembrar como era a redação original e como ficou com a nova lei:

REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI N. 8.072/90	REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.464/2007
“Art. 2.º, § 1.º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado”.	“Art. 2.º, § 1.º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”.

Ou seja, o STF, ao enfrentar o tema, decidiu que a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado, fora das regras do Código Penal, é **inconstitucional** por violar o **princípio da individualização da pena** (art. 5.º, XLVI). A definição do regime inicial de cumprimento de pena deve ser **justificada** e **declarada** pelo magistrado em cada caso concreto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado (art. 33 c/c o art. 59, do CP).

Esse entendimento foi firmado no julgamento do **HC 111.840** (Pleno, j. 27.06.2012) e tem sido a orientação da Corte (no mesmo sentido, cf. HC

113.442, 2.^a T., j. 25.06.2013, HC 107.084, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24.09.2013, 2.^a T., *DJE* de 08.10.2013 etc.).

A dúvida surge: os juízes do Brasil estão obrigados a seguir essa interpretação? **Não**. A decisão foi estabelecida em controle difuso, que não possui efeitos *erga omnes* e vinculante.

Na prática, diante do ajuizamento de reclamações (art. 102, I, “I”, CF) contra decisões que estão determinando a obrigatoriedade do cumprimento de pena inicialmente no regime fechado (aplicando, assim, a literalidade da nova lei, mesmo quando a pena for inferior a 8 anos de reclusão — art. 33, § 2.º, “a”, CP), alguns Ministros, por não se admitir o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, embora não conheçam da reclamação, estão, de ofício, concedendo *habeas corpus*. [98](#)

Essa situação, sem dúvida, propiciará (e seria conveniente) a edição de súmula vinculante sobre a matéria, até porque a Corte (8 votos contra 2) **não reconheceu a tese da mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88**, não aceitando, assim, a pretendida abstrativização do controle difuso que vinha sendo sustentada pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau (cf. [RCL 4.335](#), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.03.2014, *DJE* de 22.10.2014 e comentários no item 6.6.5 deste trabalho).

B) Retroatividade da lei penal mais benéfica

Agora, passamos a analisar a segunda hipótese, qual seja, a regra da *retroatividade da lei penal mais benéfica*.

Como se sabe, a **Lei n. 12.015/2009**, ao modificar os arts. 213 e 214 do Código Penal, deixou de fazer distinção entre crimes de *estupro* e *atentado violento ao pudor*, **unificando** os dois crimes no art. 213, podendo, assim, o estupro, na nova regra, ser praticado por homem ou mulher (**crime comum**).

Em suma, o estupro está caracterizado na hipótese de se *constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso*.

Não se trata de *abolitio criminis*, porque as condutas do crime de *atentado*

violento ao pudor, apesar de revogado o art. 214 do CP, continuam previstas no crime de estupro (agora no art. 213 do CP). A conduta, portanto, continua sendo punida.

Contudo, o STF vem aceitando a tese da **continuidade delitiva** por ter a nova lei **unificado** os arts. 213 e 214 do CP em um mesmo tipo e, assim, vale a nova regra já que mais benéfica. Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. **Mesmas circunstâncias de tempo, modo e local**. Crimes da mesma espécie. **Continuidade delitiva**. Reconhecimento. **Possibilidade**. Superveniência da Lei n. 12.015/09. **Retroatividade da lei penal mais benéfica**. Art. 5.º, XL, da Constituição Federal. HC concedido. Concessão de ordem de ofício para fins de progressão de regime. A edição da Lei n. 12.015/09 torna possível o reconhecimento da continuidade delitiva dos antigos delitos de estupro e atentado violento ao pudor, quando praticados nas **mesmas circunstâncias de tempo, modo e local** e contra a **mesma vítima**” (HC 86.110, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 02.03.2010, 2.ª Turma, DJE de 23.04.2010). [99](#)

■ **14.10.28.2. Práticas discriminatórias, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e crimes inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5.º, XLI a XLIV)**

■ **discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais:** será punida pela lei;

■ **prática do racismo:** crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

■ **crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia:** [100](#) prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Sugerimos o aprofundamento do tema nos livros de *direito penal e processual penal*. Em relação aos **crimes hediondos**, prestigiando o **princípio da presunção de inocência** (art. 5.º, LVII) e a regra contida no art. 5.º, LXVI,

a **Lei n. 11.464/2007** deu nova redação ao art. 2.º, II, da *Lei de Crimes Hediondos* (Lei n. 8.072/90), permitindo a **liberdade provisória**, nos termos dos arts. 310, parágrafo único, e 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão que tenha caráter cautelar terá de ser sempre fundamentada, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência (cf., como exemplo, no site do STJ, o *HC 134.247* — j. 13.08.2009).

Isso posto, o problema surge em relação ao **tráfico de drogas**, especialmente diante da regra do art. 44 da “*Nova Lei de Drogas*” (Lei n. 11.343/2006), que **impede a liberdade provisória** ao preso em **flagrante por tráfico**.

Apesar da literalidade da regra, alguns Ministros vêm afastando essa proibição. Como exemplo, podemos citar o Ministro Eros Grau, no julgamento do **HC 100.872**, em 05.10.2009.

Consoante noticiado, “o ministro Eros Grau, do STF, concedeu liminar em *Habeas Corpus* impetrado pela defesa de uma mulher presa em flagrante com dois papелotes de cocaína. A decisão permite que a acusada responda ao processo em liberdade. Em seu despacho, o ministro afirma que o dispositivo da nova Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06), que **impede a liberdade provisória** ao preso em flagrante por tráfico, afronta os princípios constitucionais da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III), da **presunção de inocência** (art. 5.º, LVII) e do **devido processo legal** (art. 5.º, LIV) ... Embora tenha admitido que o STF **vinha** adotando o entendimento mencionado pelo STJ, o ministro Eros Grau citou, em sua decisão, precedente do ministro Celso de Mello (**HC 97.976**), no qual afirma a violação dos princípios constitucionais acima citados, acrescentando que ‘o tema está a merecer reflexão por esta Corte, sob o ponto de vista da proibição de excessos decorrentes da atividade normativa do Estado’” (*Notícias STF*, 05.10.2009).

Cada vez mais vinha sendo observada uma mudança de entendimento por parte do STF, podendo ser referido, por exemplo, voto do Min. Dias Toffoli nos HCs 92.687 e 100.949, em 03.12.2010.

Essa tendência veio a ser confirmada, por 7 x 3, pelo Plenário do STF, no julgamento do **HC 104.339**, afetado à 2.ª Turma, tendo sido declarada a

inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória contida no art. 44 da *Lei de Drogas* (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2012, *DJE* de 06.12.2012).

O fato de serem crimes inafiançáveis não impede a liberdade provisória em razão de outros preceitos em ponderação, quais sejam, como já citado, os princípios da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III), da **presunção de inocência** (art. 5.º, LVII) e do **devido processo legal** (art. 5.º, LIV).

Dessa forma, por ter sido a decisão proferida em controle difuso, afetado ao Plenário, o Tribunal deliberou autorizar os Senhores Ministros a decidirem monocraticamente os *habeas corpus* quando o único fundamento da impetração for o art. 44 da mencionada lei, nos termos do voto do Relator.

■ **crime inafiançável e imprescritível:** ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

■ **14.10.28.3. Regras constitucionais sobre as penas (art. 5.º, XLV a XLVIII)**

■ **a pena é personalíssima:** nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

■ **tipos de pena:** a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos;

Cumprir observar que o STF, consolidando o entendimento fixado no HC 82.959, ou seja, pela observância ao princípio da **individualização da pena** (art. 5.º, XLVI), editou, em 16.12.2009, com efeito *erga omnes* e vinculante, a **SV 26/2009** (*DJE* de 23.12.2009), que tem o seguinte teor: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução

observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” (cf. *item 6.6.5.1*).

Outro tema que pode vir a ser sumulado, em razão da importância, é a discussão sobre a possibilidade ou não de **conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos** na hipótese de **tráfico de drogas**.

O art. 44 da Lei n. 11.343/2006 (*nova Lei de Drogas*) prescreve que, em relação aos crimes previstos nos arts. 33, *caput*, e § 1.º, e 34 a 37, está **vedada** a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Essa proibição consta, também, no art. 33, § 4.º, da referida lei.

Contudo, em interessante julgamento, o Pleno do STF, por **6 x 4**, declarou, incidentalmente (já que se tratava de caso concreto e, assim, do controle difuso), inconstitucional a referida proibição (**HC 97.256**, j. 1.º.09.2010, *DJE* de 15.12.2010), elencando, dentre outros argumentos, o **princípio da individualização da pena**.

Ainda, observou que “... no plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar **alternativas** ao encarceramento. É o caso da **Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas**, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma **supralegal** de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano **a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes**. 5. Ordem parcialmente concedida tão somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante do § 4.º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito *ex nunc*, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena

restritiva de direitos...” (*ementa* do referido acórdão).

- **vedação das penas:** a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis;

- **cumprimento da pena:** em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

■ 14.10.28.4. **Direitos assegurados aos presos (art. 5.º, XLIX, L, LXII, LXIII e LXIV)**

- **respeito à integridade física e moral;**

- **presidiárias:** garantias de condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

- **comunicação imediata da prisão e o local onde se encontre:** ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

- **informação ao preso de seus direitos:** dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

- **identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.**

■ 14.10.28.5. **Regras sobre extradição (art. 5.º, LI e LII)**

- **brasileiro nato:** nunca será extraditado;

- **brasileiro naturalizado:** será extraditado: a) em caso de crime comum, praticado **antes** da naturalização, ou b) de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, praticado **antes** ou **depois** da naturalização;

- **estrangeiros:** poderão ser extraditados, exceto em caso de crime político ou de opinião.

Remetemos o nosso ilustre leitor para o *capítulo 16*, no qual fizemos estudo aprofundado dos institutos em análise, diferenciando-os de asilo político, expulsão, deportação e banimento.

■ 14.10.28.6. **Presunção de inocência (não culpabilidade) (art. 5.º, LVII)**

Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, nada mais natural que a inversão do ônus da prova, ou seja, a inocência é presumida, cabendo ao MP ou à parte acusadora (na hipótese de ação penal privada) provar a culpa. Caso não o faça, a ação penal deverá ser julgada improcedente.

De maneira precisa anotam Bechara e Campos: “melhor denominação seria **princípio da não culpabilidade**. Isso porque a Constituição Federal não presume a inocência, mas declara que ninguém será considerado **culpado** antes de sentença condenatória transitada em julgado”. [101](#)

Como reflexo, destacamos a abolição do lançamento do nome do acusado no rol dos culpados quando da pronúncia.

Lembramos, outrossim, a S. 716/STF, que admite “a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Consoante anotado pelos ilustres professores, “... tem-se uma hipótese de antecipação dos efeitos da condenação transitada em julgado, contudo, a mitigação do princípio da presunção de inocência é justificada pelo princípio do *favor rei* ou *favor libertatis*, igualmente de índole constitucional”. [102](#)

Finalmente, cabe notar que o STF, por 7 x 4, pacificou o entendimento de que a **execução da pena privativa de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, contraria o artigo 5.º, LVII, da Constituição** (HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, j. 05.02.2009, *Inf.* 534/STF). Alerta-se que ficou **ressalvada** a eventual possibilidade de **prisão cautelar do réu**, nas hipóteses do CPP.

■ 14.10.28.7. Regras sobre a prisão (art. 5.º, LXI, LXV, LXVI, LXVII)

■ **prisão:** somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (*vide* também art. 136, § 3.º, I, no caso de estado de defesa);

■ **prisão ilegal:** será imediatamente **relaxada** pela autoridade judiciária;

■ **admissão pela lei de liberdade provisória, com ou sem fiança:** ninguém será levado à prisão ou nela mantido;

■ **prisão civil:** não é admitida, salvo a do responsável pelo *inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia* e a do *depositário infiel*.

CUIDADO: em relação à prisão civil e conforme já estudamos (*item 9.14.5.2.3*), o STF entendeu que **não cabe mais a prisão do depositário infiel**.

Por 5 x 4, em **03.12.2008**, no julgamento do **RE 466.343**, o STF decidiu que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se não incorporados na forma do art. 5.º, § 3.º (quando teriam natureza de norma constitucional), têm natureza de normas **supralegais**, paralisando, assim, a eficácia de todo o ordenamento infraconstitucional em sentido contrário.

Como se sabe, o Brasil é signatário de tratados internacionais que não mais estabelecem prisão do depositário infiel.

Sobre o tema, decidiu o Min. Gilmar Mendes, “... **a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel** (art. 5.º, inciso LXVII, que ainda persiste, acrescente-se) **não foi revogada** pela ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos — Pacto de San José da Costa Rica (art. 7.º, 7), **mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria**, incluídos o art. 1.287 do Código Civil de 1916 (e agora o Novo CC, acrescente-se) e o Decreto-lei n. 911, de 1.º de outubro de 1969” (*Inf. 449/STF*).

Pondo fim a qualquer discussão, o STF editou a **SV 25/2009**: “é **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

■ **14.10.28.8. Identificação criminal (art. 5.º, LVIII)**

O civilmente identificado **não** será submetido a identificação criminal (pelo processo datiloscópico, se possível, e pela juntada aos autos da folha de antecedentes — art. 6.º, VIII, do CPP), salvo nas hipóteses previstas em lei (art. 5.º, LVIII). Nesse sentido, acompanhamos a posição do Professor Damásio, que entende que a Súmula 568 do STF foi cancelada, só se procedendo à identificação criminal se não tiver sido realizada a civil, ou em casos excepcionais, como a falta de apresentação do documento, rasuras, indícios de falsificação etc. [103](#)

A **Lei n. 12.037, de 1.º.10.2009**, que regulamentou a matéria, abarcando a regra geral da **não identificação criminal** (processo datiloscópico e fotográfico) do civilmente identificado, alinhou as hipóteses em que, mesmo ao civilmente identificado, se procederá à identificação criminal. Isso ocorrerá, segundo a lei, de acordo com seu art. 3.º, quando:

- o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
- o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
- o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
- a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
- constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
- o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da

expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

■ 14.10.28.9. Ação penal privada subsidiária da pública (art. 5.º, LIX)

A ação penal pública é **privativa** do Ministério Público (art. 129, I). Trata-se de princípio **absoluto**. No entanto, havendo **inércia** do Ministério Público (seja pelo não oferecimento de denúncia, seja pelo não requerimento de arquivamento do inquérito policial, ou mesmo pela falta de requisição de novas diligências no prazo legal), será admitida ação privada, porém sem retirar o caráter de privatividade da ação penal pública do Ministério Público (*vide* arts. 5.º, LIX, da CF e 29 do CPP. Cf., ainda, Inq. 172-SP — *RTJ* 112/474; HC 67.502-RJ — *RTJ* 130/1084; HC 74.276-RS e *Inf.* 43/STF, 1996).

Evocando os princípios da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III), da **igualdade substancial** (art. 5.º, I), do **dever da lei de punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais** (art. 5.º, XLI), bem como a regra do art. 226, § 8.º, da CF/88, segundo a qual o Estado assegurará a assistência a família na pessoa de cada um dos que a integram, criando **mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações**, o STF, dando interpretação conforme a Constituição aos arts. 12, I, e 16 da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), estabeleceu que a ação penal para a apuração dos delitos de lesão corporal leve e culposa domésticos contra a mulher **independem de representação da vítima**. Trata-se, portanto, de **ação penal pública incondicionada** (cf. **ADC 19** e **ADI 4.424**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.02.2012, Plenário, *Inf.* 654/STF, bem como *item 19.9.5*).

■ 14.10.29. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV)

■ 14.10.29.1. Aspectos gerais

Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Corolário a esse princípio, asseguram-se aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Destacamos a [SV 21/STF](#), com o seguinte teor: “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.

Ainda, a [SV 28/STF](#), que fixa o seguinte entendimento: “é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”. Referido depósito prévio, além de violar o art. 5.º, LV, afrontaria, também, o art. 5.º, XXXV, que trata do princípio na inafastabilidade.

Outro ponto é a regra firmada na [SV 5/STF](#): “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, o que já discutimos no *item 12.5.4*, ao qual remetemos o nosso ilustre leitor.

E como esses princípios devem ser analisados no inquérito policial?

Referido procedimento não caracteriza, ainda, a acusação. Fala-se em **indiciado**, já que o inquérito policial é mero **procedimento administrativo** que busca colher provas sobre o fato infringente da norma e sua autoria.

Conforme anotaram Bechara e Campos, “ocorre, todavia, que muito embora não se fale na incidência do princípio durante o inquérito policial, é possível visualizar alguns atos típicos de contraditório, os quais não afetam a natureza inquisitiva do procedimento. Por exemplo, o interrogatório policial e a nota de culpa durante a lavratura do auto de prisão em flagrante”. [104](#)

Vale lembrar que “ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo” (*Inf. 366/STF*, HC 84.517/SP, Rel. Sepúlveda Pertence, 19.10.2004. Precedentes citados: HC 74.368/MG, *DJU* de 28.11.1997, e HC 81.171/DF, *DJU* de 07.03.2003).

Destacamos, finalmente, a **SV 14/STF**: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

■ 14.10.29.2. *Interrogatório por videoconferência (on-line)*

A possibilidade de se implementar o interrogatório por videoconferência está relacionada à aplicação do princípio da proporcionalidade a resolver a colisão entre dois direitos fundamentais, quais sejam, a **ampla defesa e o direito de presença**, de um lado, e a **segurança e ordem pública**, a ensejar a **eficiência**, de outro.

Nessa linha, “o que deve autorizar o uso da técnica, contudo, é o fundado receio de comprometimento da eficiência do processo, seja por razões de segurança ou ordem pública, seja porque o processo guarda certa complexidade, e a participação à distância resulte necessária para evitar o atraso no seu andamento”. [105](#)

O STJ havia pacificado entendimento pela aceitação do interrogatório on-line: “Recurso ordinário em *habeas corpus*. Processual penal. Interrogatório realizado por meio de sistema de **videoconferência** ou **teleaudiência** em *real time*. Cerceamento de defesa. Nulidade, para cujo reconhecimento faz-se necessária a ocorrência de efetivo prejuízo, não demonstrado, no caso” (RHC 15.558/SP, 5.^a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, *DJ* de 11.10.2004. Nesse sentido, cf. STJ, RHC 6.272-SP, *RT* 742/579, e RHC 8.742-SP).

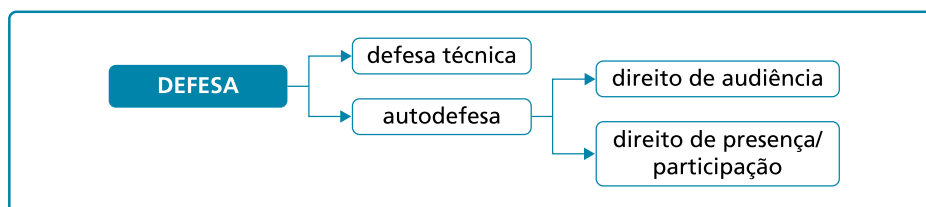
No Estado de São Paulo, a **Lei n. 11.819, de 05.01.2005**, dispunha sobre a implantação de aparelhos de videoconferência para interrogatório e audiências de

presos a distância.

Em termos de expectativa sobre a videoconferência, a única pesquisa encontrada foi do site “Infojus” (<www.infojus.gov.br>), que “promove enquetes para saber a opinião dos internautas sobre assuntos que dizem respeito ao funcionamento do Judiciário brasileiro”, refletindo uma primeira desconfiança do sistema (cf. *Notícias STF*, 09.02.2004 — 16h02):

ENQUETE INFOJUS SOBRE A VIDEOCONFERÊNCIA	
■ 31% — favorável, pois agilizaria o processo criminal e ofereceria mais segurança ao juiz e à comunidade.	
■ 66% — contra. Sem o contato pessoal com o juiz, o réu ficaria tolhido em seu amplo direito de defesa.	
■ 3% — Ainda não tem opinião formada.	

Apesar de a Ministra Ellen Gracie ter proferido decisão admitindo a videoconferência (HC 91.758, j. 11.07.2007), a 2.^a Turma do STF, em julgamento posterior, entendeu **incabível** o interrogatório on-line. Pedimos vênia para reproduzir o *Inf. 476/STF*, destacando-se as modalidades de defesa abaixo esquematizadas:



“Inicialmente, aduziu-se que a defesa pode ser exercitada na conjugação da defesa técnica e da autodefesa, esta, consubstanciada nos direitos de audiência e de presença/participação, sobretudo no ato do interrogatório, o qual deve ser

tratado como meio de defesa. Nesse sentido, asseverou-se que o princípio do devido processo legal (CF, art. 5.º, LV) pressupõe a regularidade do procedimento, a qual nasce da observância das leis processuais penais. Assim, nos termos do Código de Processo Penal, a regra é a realização de audiências, sessões e atos processuais na sede do juízo ou no tribunal onde atua o órgão jurisdicional (CPP, art. 792), não estando a videoconferência prevista no ordenamento. E, suposto a houvesse, a decisão de fazê-la deveria ser motivada, com demonstração de sua excepcional necessidade no caso concreto, o que não ocorreria na espécie. Ressaltou-se, ademais, que o projeto de lei que possibilitava o interrogatório por meio de tal sistema (PL 5.073/2001) fora rejeitado e que, de acordo com a lei vigente (CPP, art. 185), o acusado, ainda que preso, deve comparecer perante a autoridade judiciária para ser interrogado. Entendeu-se, no ponto, que em termos de garantia individual, o virtual não valeria como se real ou atual fosse, haja vista que a expressão ‘perante’ não contemplaria a possibilidade de que esse ato seja realizado on-line. Afastaram-se, ademais, as invocações de celeridade, redução dos custos e segurança referidas pelos favoráveis à adoção desse sistema. Considerou-se, pois, que o interrogatório por meio de teleconferência viola a publicidade dos atos processuais e que o prejuízo advindo de sua ocorrência seria intuitivo, embora de demonstração impossível. Concluiu-se que a inteireza do processo penal exige defesa efetiva, por força da Constituição que a garante em plenitude, e que, quando impedido o regular exercício da autodefesa, em virtude da adoção de procedimento sequer previsto em lei, restringir-se-ia a defesa penal” (*Inf. 476/STF — HC 88.914, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.08.2007, DJ de 05.10.2007*).

Em 30.10.2008, finalmente, o STF, por 9 x 1, entendeu inconstitucional a lei paulista (Lei estadual n. 11.819/2005), na medida em que a **competência para legislar sobre processo é da União** (art. 22, I).

Estamos, pois, diante do reconhecimento de **vício formal** (competência para legislar sobre processo — art. 22, I —, **não** se tratando de procedimento em matéria processual — art. 24, XI), não tendo sido analisado o mérito, qual seja, se a videoconferência poderia caracterizar violação aos princípios do devido

processo legal, contraditório, ampla defesa, publicidade, isonomia etc.

Referido julgamento foi proferido no **HC 90.900**, tendo o STF anulado o processo desde o interrogatório e, assim, concedido alvará de soltura para réu, no caso, condenado por roubo qualificado.

Em **18.11.2008**, a 2.^a Turma do STF anulou a condenação de réu pelo crime de tráfico de drogas, determinando a realização de novo interrogatório judicial, expedindo, também, alvará de soltura, se não estivesse preso por outro crime (HC 91.758).

Pouco tempo depois, o Congresso Nacional aprovou a **Lei n. 11.900, de 08.01.2009**, alterando dispositivos do CPP, para prever a possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais por sistema de **videoconferência**, além de dar outras providências.

O interrogatório do réu preso por sistema de **videoconferência** ou **outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real** passa a ser a **exceção**, podendo ser realizado pelo juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes e desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

- prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;
- viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
- impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal;
- responder a gravíssima questão de ordem pública.

Resta aguardar como o STF se posicionará sobre a matéria, que, em nosso entender, mostra-se **adequada** e dentro da **realidade da sociedade moderna**, sendo, ainda, a nova sistemática prevista como **exceção** à regra geral, que

assegura o direito de audiência e de presença (participação).

Segundo o Deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), o projeto, agora convertido na citada Lei n. 11.900/2009, vai representar uma **economia anual da ordem de R\$ 1 bilhão aos cofres públicos**. “Em São Paulo, a média de gastos por semana é de R\$ 17 milhões. Se formos transferir esses gastos, a nação gasta R\$ 1,5 bilhão em recursos humanos e materiais só para a remoção de presos...” (Folha Online, 09.12.2008 — 20h49).

■ 14.10.29.3. **Transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima**

A **Lei n. 11.671/2008** dispôs sobre a transferência e inclusão de presos em **estabelecimentos penais federais de segurança máxima** no **interesse da segurança pública** ou do **próprio preso**, condenado ou provisório, sempre de **modo excepcional** e por **prazo determinado**, não podendo o período de transferência ser superior a 360 dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.

De acordo com a lei, são **legitimados** para requerer o processo de transferência, *cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima*, a **autoridade administrativa**, o **Ministério Público** e o **próprio preso**.

A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de **decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente**, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

A lei determina ainda, por regra, que, antes da transferência, sejam ouvidos, no prazo de 5 dias cada, quando não requerentes, a **autoridade administrativa**, o **Ministério Público** e a **defesa**, bem como o **Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)**, ao qual é facultado indicar o estabelecimento penal federal

mais adequado.

Havendo **extrema necessidade**, contudo, o **juiz federal** poderá autorizar a **imediata transferência** do preso e, após a instrução dos autos, na forma do § 2.º, do art. 5.º, da Lei n. 11.671/2008, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada (art. 5.º, § 6.º).

Essa oitiva postergada, desde que fundamentada, não viola, segundo o STF, o devido processo legal, a ampla defesa, a individualização da pena e a dignidade da pessoa humana. [106](#)

■ 14.10.29.4. **Art. 98 do antigo Regimento Interno do CNJ: necessidade de intimação pessoal de terceiros que demonstrem interesse jurídico nos procedimentos de controle administrativo (PCAs). Correção no novo RI**

O art. 98 do **antigo** *Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça — RICNJ* (Res. n. 2/2005) estabelecia que, em *procedimento de controle dos atos administrativos* (PCAs) praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, o Relator determinaria a oitiva da autoridade que praticou o ato impugnado e, **por edital**, dos eventuais beneficiários de seus efeitos, no prazo de 15 dias.

O STF declarou, *incidentalmente*, em caso concreto, a inconstitucionalidade de referido dispositivo, que aceitava a intimação por edital, por ofender o art. 5.º, LV, da CF.

Tratava-se de MS impetrado contra ato do CNJ que havia anulado o *III Concurso das Serventias Extrajudiciais do Estado de Rondônia*. “Ressaltou-se que, veiculada a classificação dos candidatos mediante edital, os impetrantes passaram a ter situação jurídica constituída que somente poderia ser afastada, presente o regular processo administrativo, se cientificados do pleito de irresignação de certos candidatos, para, querendo, oferecerem impugnação. Aduziu-se que, **conhecidos os beneficiários do ato**, deveria ocorrer a **ciência respectiva**, não podendo esta se verificar de **forma ficta**, ou seja, por **edital**. Esclareceu-se que os beneficiários do ato não teriam sequer conhecimento da existência do processo no CNJ, não lhes competindo acompanhar a vida

administrativa deste último, inclusive o que lançado em edital cuja veiculação se mostrou estritamente interna. Assentou-se que se deveria conferir a eficácia própria ao art. 100 do *RICNJ* a preceituar a aplicabilidade, no que couber, da Lei 9.784/99 que prevê a **necessária intimação dos interessados** (artigos 3.º, II; 26, §§ 3.º e 4.º, e 28)” (**MS 25.962**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.10.2008, *Inf.* 525/STF).

Nesse sentido, de maneira interessante, o **novo** Regimento Interno do CNJ (Resolução n. 67, de 03.03.2009), em seu art. 94, dispõe que o Relator, nos PCAs, ao determinar a notificação da autoridade que praticou o ato impugnado e dos **eventuais interessados** em seus efeitos, no prazo de 15 dias, poderá estabelecer as formas e os meios de **notificação pessoal** a estes últimos, sendo a utilização do **edital** apenas quando dirigida a eventuais interessados **não identificados, desconhecidos** ou com **domicílio não informado** nos autos.

■ 14.10.30. Devido processo legal substantivo ou material (arts. 5.o, LV, e 3.o, I)

Segundo ensina Olavo Ferreira, “o princípio do devido processo legal tem duas facetas: 1) formal e 2) material. Esta segunda encontra fundamento nos artigos 5.º, inciso LV, e 3.º, inciso I, da Constituição Federal. Do devido processo legal substancial ou material são extraídos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há repercussão prática na discussão sobre a origem do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se que os mesmos têm *status* constitucional, e diante de tal situação todos os atos infraconstitucionais devem com eles guardar relação de compatibilidade, sob pena de irremissível inconstitucionalidade, reconhecida no controle difuso ou concentrado ... A razoabilidade e proporcionalidade das leis e atos do Poder Público são inafastáveis, considerando-se que o Direito tem conteúdo justo”. [107](#)

Como parâmetro, devem ser observados três importantes requisitos: [108](#)

■ **necessidade:** por alguns denominada **exigibilidade**, a adoção da medida que possa restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra menos gravosa;

■ **adequação:** também denominada **pertinência** ou **idoneidade**, quer significar que o meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido;

■ **proporcionalidade em sentido estrito:** em sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, em termos de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outros valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima efetividade e mínima restrição.

■ 14.10.31. Provas ilícitas (art. 5.º, LVI)

As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. [109](#) Desse princípio decorre também o de que as provas derivadas de provas obtidas por meios ilícitos também estarão maculadas pelo vício da ilicitude, sendo, portanto, inadmissíveis (**teoria dos frutos da árvore envenenada**).

Conforme aponta Alexandre de Moraes, citando jurisprudência do STF, “a regra deve ser a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, que só excepcionalmente deverão ser admitidas em juízo, em respeito às liberdades públicas e ao princípio da dignidade humana na colheita de provas e na própria persecução penal do Estado”. [110](#)

Essa convalidação da prova ilícita implementa-se em razão da legítima defesa e pode ser pensada na interceptação de uma carta de sequestrador, na gravação de uma triste e covarde cena de babá “espancando” uma criança etc.

■ 14.10.32. Publicidade dos atos processuais (e dever de motivação das decisões judiciais) (art. 5.º, LX). Perspectivas do CPC/2015

Dentre vários outros instrumentos garantidores da imparcialidade do juiz, mesmo com o aumento de seus poderes instrutórios, está o dever de **motivar** as

decisões jurisdicionais.

O art. 93, IX, da CF/88, na redação determinada pela **EC n. 45/2004**, determina que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de **nulidade**, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, **em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação**”.

Trata-se do denominado **segredo de justiça**, que, pela *Reforma do Judiciário*, foi limitado. Isso porque o direito subjetivo das partes e advogados à intimidade somente estará garantido **se não prejudicar o interesse público à informação**.

Complementando essa garantia geral do dever de motivação e publicidade das decisões, o art. 5.º, LX, da CF/88 estabelece que *a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem*. Assim, totalmente aceitáveis as regras fixadas, por exemplo, nos arts. 155, 444, 815 e 841 do CPC/73 (tendo os dois primeiros correspondências nos arts. 189 e 368 do CPC/2015) e 20 do CPP.

Pelo exposto, o dever de motivar as decisões judiciais (o “livre convencimento motivado” — CPC/73, arts. 131, 165, 458 — com correspondência nos arts. 371, 11 e 489 do CPC/2015; CPP, art. 381, III etc.) deve ser entendido, numa visão moderna do direito processual, não somente como garantia das partes. Isso porque, em virtude da **função política da motivação das decisões**, pode-se afirmar que os seus destinatários “... não são apenas as partes e o juiz competente para julgar eventual recurso, mas *quisquis de populo*, com a finalidade de aferir-se em concreto a imparcialidade do juiz e a legalidade de justiça das decisões”. [111](#)

Conforme anota Streck, a substituição da expressão “o juiz apreciará **livremente** a prova” (art. 131, CPC/73) pela “o juiz apreciará a prova” (CPC/2015), sem a palavra “livremente”, tem um significado muito grande no sentido de combate ao “voluntarismo judicial” e em busca da concretização de

uma jurisprudência íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015). [112](#)

O art. 489, § 1.º, CPC/2015, estabelece parâmetros mínimos e de qualidade para que a **decisão judicial** (e o texto fala em “decisão judicial”, e não apenas “sentença”) seja considerada fundamentada. [113](#)

Conforme destacou Gonçalves, “ao indicar os elementos da sentença, o legislador foi particularmente cuidadoso quanto à exigência de fundamentação. No CPC de 1973, ela também é indispensável, pois se trata de exigência constitucional. Mas o § 1.º do art. 486 do CPC de 2015 enumera, em seis incisos, hipóteses em que não se considera fundamentada, não apenas a sentença, mas qualquer decisão judicial. A solução do legislador foi aqui bastante engenhosa, pois seria difícil indicar quais as exigências para que a decisão se considere fundamentada, sendo mais fácil enumerar as situações em que ela não será reputada como tal”. [114](#)

Encontrando total consonância com a Constituição, o art. 11 do CPC/2015, mais amplo que o art. 165 do CPC/73, estabelece a regra geral: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e **fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade**”.

■ 14.10.33. Assistência jurídica integral e gratuita (art. 5.º, LXXIV)

O art. 5.º, LXXIV, dispõe que o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Esse direito e garantia fundamental instrumentaliza-se por meio da **Defensoria Pública**, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do citado inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal (art. 134, *caput*, da CF/88).

A instituição é fortalecida pela **EC n. 45/2004**, que assegura às Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa e fixa competência para

proposta orçamentária, conforme o § 2.º, inserido no art. 134, com a seguinte redação: “às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2.º”.

Em igual sentido, a **EC n. 69/2012** altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a **Defensoria Pública do Distrito Federal**. De acordo com o art. 2.º da referida emenda constitucional, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.

Por sua vez, a **EC n. 74/2013** determinou a aplicação do citado art. 134, § 2.º (autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária), às **Defensorias Públicas da União** e do **Distrito Federal**. Assim, inovou em relação à primeira e explicitou em relação à segunda o que já havia sido assegurado pela EC n. 69/2012.

Finalmente, a **EC n. 80/2014**, de maneira impressionante e histórica, aloca a defensoria pública em **seção própria** do capítulo IV, do Título IV, da Constituição, desvinculando-a da seção que trata da advocacia privada.

Remetemos o leitor atento para o *item 12.6*, onde estudamos com maior detença o assunto. Esse tema é de fundamental importância àqueles que se concentram para concursos de Defensor Público. Vamos em frente...

■ 14.10.34. Erro judiciário (art. 5.º, LXXV)

O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Prepondera o entendimento de que “o Estado não é civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário, senão nos casos expressamente declarados em lei” (STF, *RDA* 114/298; *RT* 150/363; *RTJ* 64/689), vale dizer, nas hipóteses prescritas no art. 49 da Lei Complementar n. 35/79, [115](#) no art. 133 do

CPC/73¹¹⁶ e no art. 630 do CPP,¹¹⁷ tendo sido o § 2.º deste último, na opinião deste autor, a despeito de posicionamentos em contrário,¹¹⁸ revogado por falta de compatibilização com o art. 5.º, LXXV, da CF/88, que tornou incondicional a indenização por **erro judiciário**.¹¹⁹

Nelson Nery Junior observa: “mais específica do que a garantia de indenização da CF, art. 37, § 6.º, aqui foi adotada a responsabilidade objetiva fundada na *teoria do risco integral*, de sorte que não pode invocar-se nenhuma causa de exclusão do dever de o Estado indenizar quando ocorrer o erro judiciário ou a prisão por tempo além do determinado na sentença”.¹²⁰ Nessa linha:

“Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, art. 5.º, LXXV. C. Pr. Penal, art. 630. O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 5.º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6.º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. O art. 5.º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário *stricto sensu*, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça” (RE 505.393, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 26.06.2007, DJ de 05.10.2007).

■ 14.10.35. Gratuidade das certidões de nascimento e de óbito (art. 5.º, LXXVI)

O art. 5.º, LXXVI, estatui serem gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o *registro civil de nascimento* e a *certidão de óbito*.

O art. 236, por seu turno, fixa que os serviços notariais e de registro são exercidos em *caráter privado*, por delegação do Poder Público, observando-se a regra específica do art. 32 do ADCT.

Como se sabe, nos termos do art. 236, § 3.º, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 meses.

Essa regra vem motivando vários candidatos a prestar o difícil concurso público para o exercício da atividade notarial e de registro.

Em relação à gratuidade das aludidas certidões, resta saber se seria somente para os reconhecidamente pobres ou para todos.

Os arts. 1.º, 3.º e 5.º da Lei n. 9.534/97, alterando o art. 30 da Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos); acrescentando um inciso VI ao art. 1.º da Lei n. 9.265/96; e alterando o art. 45 da Lei n. 8.935/94, respectivamente, ao considerar como ato necessário ao exercício da cidadania, estabeleceu serem **gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão respectiva**.

Percebe-se que a lei não fez nenhuma restrição, abrangendo os reconhecidamente pobres ou não, ou seja, ampliativamente, estende-se a todos, brasileiros e, inclusive, estrangeiros, pobres ou não.

Referido dispositivo foi questionado perante o STF: “O Tribunal, por maioria, deferiu o pedido de liminar em ação declaratória de constitucionalidade promovida pelo Procurador-Geral para, com eficácia *ex nunc* e efeito vinculante, suspender, até decisão final da ação, a prolação de qualquer decisão, assim como os efeitos de todas as decisões não transitadas em julgado e de todos os atos normativos que digam respeito à legitimidade constitucional, eficácia e aplicação dos arts. 1.º, 3.º e 5.º da Lei n. 9.534/97, que prevê a gratuidade do registro civil de nascimento, do assento de óbito, bem como da primeira certidão respectiva. Considerou-se inexistir conflito da Lei 9.534/97 com os arts. 5.º, LXXVI, e 236

da CF, dado que o inciso LXXVI do art. 5.º da CF, ao assegurar a gratuidade desses atos aos reconhecidamente pobres, determina o mínimo a ser observado pela lei, não impedindo que esta garantia seja ampliada, e, também, pelo fato de que os atos relativos ao nascimento e ao óbito são a base para o exercício da cidadania, sendo assegurada pela CF a gratuidade de todos os atos necessários ao seu exercício (CF, art. 5.º, LXXVII). Salientou-se, ainda, que os oficiais exercem um serviço público, prestado mediante delegação, não havendo direito constitucional a percepção de emolumentos por todos os atos praticados, mas apenas o recebimento, de forma integral, da totalidade dos emolumentos que tenham sido fixados...” (Inf. 171/STF).

Ao final, o STF julgou o mérito, tanto da **ADI 1.800** como da **ADC 5**, e, nas duas, declarou constitucional a Lei n. 9.534/97, que isenta a todos, **independentemente de sua condição ou situação econômica**, do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. [121](#)

■ 14.10.36. Gratuidade nas ações de *habeas corpus* e *habeas data* (art. 5.º, LXXVII)

O art. 5.º, LXXVII, prevê serem gratuitas as ações de *habeas corpus* e *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

A nosso ver o constituinte deveria, de modo expresso, ter estendido esse benefício também às outras ações constitucionais.

Em relação aos atos necessários ao exercício da cidadania, o art. 1.º da Lei n. 9.265/96, que regulamenta o aludido direito fundamental, prescreve como gratuitos os seguintes atos:

- os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o art. 14 da Constituição;
- aqueles referentes ao alistamento militar;
- os pedidos de informações ao Poder Público, em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades

administrativas na órbita pública;

- as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude;

- quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público;

- o registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva (acrescentado pelo art. 3.º da Lei n. 9.534/97 — cf. comentários ao inciso LXXVI do art. 5.º, *supra*, e o julgamento final da constitucionalidade definitiva deste artigo — ADI 1.800-DF e ADC 5-DF).

■ 14.10.37. Celeridade processual (art. 5.º, LXXVIII)

■ 14.10.37.1. Aspectos gerais

Atualmente, muito se fala na busca da **efetividade do processo** em prol de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça.

Em outro estudo [122](#) observamos que, “em algumas situações, contudo, a demora, causada pela duração do processo e sistemática dos procedimentos, pode gerar total inutilidade ou ineficácia do provimento requerido. Conforme constatou Bedaque, ‘o tempo constitui um dos grandes óbices à efetividade da tutela jurisdicional, em especial no processo de conhecimento, pois para o desenvolvimento da atividade cognitiva do julgador é necessária a prática de vários atos, de natureza ordinatória e instrutória. Isso impede a imediata concessão do provimento requerido, o que pode gerar risco de inutilidade ou ineficácia, visto que muitas vezes a satisfação necessita ser imediata, sob pena de perecimento mesmo do direito reclamado’”. [123](#)

Nesse sentido, a **EC n. 45/2004**, ampliando os direitos e garantias fundamentais, estabeleceu, no art. 5.º, LXXVIII, que a todos, no âmbito **judicial** e **administrativo**, são assegurados a **razoável duração do processo** [124](#) e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**.

Trata-se, sem dúvida, de garantia não só restrita a **brasileiros natos** ou **naturalizados** e a **estrangeiros residentes no País**, mas que abarca também — corroborando entendimento do STF e da doutrina, interpretando o *caput* do art. 5.º da CF/88, que proclama a igualdade de **todos** perante a lei e, aqui tomado por analogia — os **estrangeiros não residentes** (por exemplo, de passagem, a turismo), os **apátridas** e as **pessoas jurídicas**.

A **prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável e efetivo** já vinha prevista, como direito fundamental do ser humano, dentre outros dispositivos, nos arts. 8.º, 1.º, e 25, 1.º, da *Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)*.¹²⁵

Resta não se conformar com a aludida previsão, já que, como o comando determina, são assegurados **os meios que garantam a celeridade da tramitação do processo**.

Como sinalizou Grinover, “esses meios devem ser inquestionavelmente oferecidos **pelas leis processuais**, de modo que a **reforma infraconstitucional fica umbilicalmente ligada à constitucional**, derivando de ordem expressa da Emenda n. 45/2004. Trata-se, portanto, de fazer com que a legislação processual ofereça soluções hábeis à desburocratização e simplificação do processo, para garantia da celeridade de sua tramitação”.¹²⁶

Dentro dessa perspectiva, em **15.12.2004**, foi assinado pelos Presidentes do Executivo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF, ou seja, pelos Presidentes dos três Poderes, o **I Pacto Republicano**, por um *Judiciário mais Rápido e Republicano*, buscando implementar a *Reforma do Poder Judiciário*, destacando-se *11 compromissos fundamentais* no combate à morosidade processual.¹²⁷

Em **13.04.2009**, considerando que o primeiro pacto “... permitiu a **colaboração efetiva** dos três Poderes na realização de indispensáveis reformas processuais e atualização de normas legais”; considerando que a efetividade das medidas adotadas indica que tais compromissos devem ser reafirmados e ampliados para fortalecer a proteção aos **direitos humanos**, a **efetividade da prestação jurisdicional**, o **acesso universal à Justiça** e também o

aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça, os Presidentes dos Poderes assinaram o **II Pacto Republicano de Estado** *por um Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo*.¹²⁸

Até o fechamento desta edição, o **III Pacto Republicano** ainda não havia sido assinado formalmente pelos Presidentes dos três Poderes, apesar de sugerido e lançado pelo Min. Peluso, em 1.º.02.2011, na solenidade de abertura do *Ano Judiciário de 2011*.

Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional a denominada **“PEC dos Recursos”**, com redação sugerida pelo Min. Peluso e que tomou o número-**15/2011-SF**,¹²⁹ a qual, dentro do contexto de eficiência, “propõe a imediata execução das decisões judiciais, logo após o pronunciamento dos tribunais de segunda instância (Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais). Não haverá alteração nas hipóteses de admissibilidade dos recursos extraordinário (para o STF) e especial (para o STJ), mas ela não impedirá o trânsito em julgado da decisão contra a qual se recorre. A PEC acaba com o efeito suspensivo aos recursos, facultando ao ministro relator, se for o caso, pedir preferência no julgamento” (*Notícias STF*, 21.03.2011).

De acordo com a redação da referida PEC, criam-se **ações rescisórias extraordinária e especial**, em substituição aos recursos extraordinário e especial (**matéria pendente**).

Finalmente, destacamos o **Novo Código de Processo Civil** (Lei n. 13.105/2015) com importantes instrumentos de celeridade e grandes avanços.

■ **14.10.37.2. Celeridade do processo e crimes praticados contra os idosos**

O art. 94 do **Estatuto do Idoso** (Lei n. 10.741/2003) estabelece que aos crimes previstos na referida Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, **aplica-se o procedimento previsto na Lei n. 9.099/95** (Juizados) e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e

do Código de Processo Penal.

Esse dispositivo foi questionado na [ADI 3.096](#), ajuizada pelo PGR, e entendeu o STF que a aplicação da Lei n. 9.099/95 é apenas em relação aos aspectos processuais, buscando, na ideia de efetividade do processo, que este termine mais rapidamente, até porque a vítima é um idoso:

“EMENTA: (...). Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão ‘do Código Penal e’. Aplicação **apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95**: benefício do idoso com a celeridade processual. **Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime**. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003” (ADI 3.096, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.06.2010, Plenário, *DJE* de 03.09.2010).

■ **14.10.37.3. Leis infraconstitucionais decorrentes da EC n. 45/2004 (“Reforma do Poder Judiciário”) [130](#) no sentido de “racionalização da prestação jurisdicional” — frutos dos “Pactos Republicanos”**

Cumprindo o comando fixado na **Reforma do Judiciário** (art. 7.º da EC n. 45/2004 e art. 5.º, LXXVIII, da CF/88), enumeramos algumas leis que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, na busca de maior **racionalização da prestação jurisdicional**:[131](#)

■ **Lei n. 13.105, de 16.03.2015** — disciplina o Novo Código de Processo Civil;

■ **Lei n. 12.763, de 27.12.2012** — cria 789 cargos de Defensor Público Federal no quadro da Defensoria Pública da União;

■ **Lei n. 12.726, de 16.10.2012** — acrescenta parágrafo único ao art. 95 da Lei n. 9.099/95, para dispor sobre o Juizado Especial Itinerante;

■ **Lei n. 12.694, de 24.07.2012** — dispõe sobre o processo e o

julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas;

■ **Lei n. 12.681, de 04.07.2012** — institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas — SINESP, com a finalidade de armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com: a) segurança pública; b) sistema prisional e execução penal; e c) enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas;

■ **Lei n. 12.665, de 13.06.2012** — dispõe sobre a criação de estrutura permanente para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais e cria os respectivos cargos de Juizes Federais;

■ **Lei n. 12.562, de 23.12.2011** — regulamenta o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para dispor sobre o processo e o julgamento da representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal;

■ **Lei n. 12.322, de 08.09.2010** — transforma o agravo de instrumento interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial em agravo nos próprios autos, alterando dispositivos do CPC/73;

■ **Lei n. 12.153, de 22.12.2009** — dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

■ **Lei n. 12.106, de 02.12.2009** — cria, no âmbito do CNJ, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e dá outras providências;

■ **Lei n. 12.063, de 27.10.2009** — acrescenta à Lei n. 9.868/99, o Capítulo II-A, que estabelece a disciplina processual da ação direta de inconstitucionalidade por omissão — **ADO**;

■ **LC n. 132, de 07.10.2009** — altera dispositivos da LC n. 80/94, fortalecendo a Defensoria Pública;

■ **Lei n. 12.019, de 21.08.2009** — insere inciso III no art. 3.º da Lei n. 8.038/90, para prever a possibilidade de o relator de ações penais de

competência originária do STJ e do STF convocar desembargadores de Turmas Criminais dos TJs ou dos TRFs, bem como juízes de varas criminais da Justiça dos Estados e da Justiça Federal, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período, até o máximo de 2 anos, para a realização do interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local onde se deva produzir o ato;

■ **Lei n. 12.016, de 07.08.2009** — disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências;

■ **Lei n. 12.012, de 06.08.2009** — altera o CP, passando a tipificar como crime o ingresso de pessoa portando aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional;

■ **Lei n. 12.011, de 04.08.2009** — cria 230 Varas Federais, destinadas, precipuamente, à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no País. De maneira adequada, a localização das varas será estabelecida pelo **Conselho da Justiça Federal**, com base em critérios técnicos objetivos que identifiquem a necessidade da presença da Justiça Federal na localidade, levando-se em conta, principalmente, a demanda processual, inclusive aquela decorrente da competência delegada, a densidade populacional, o índice de crescimento demográfico, o Produto Interno Bruto, a distância de localidades onde haja vara federal e as áreas de fronteiras consideradas estratégicas;

■ **Lei n. 11.969, de 06.07.2009** — altera a redação do § 2.º do art. 40 do CPC/73, estabelecendo que, sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão os seus procuradores retirar os autos, **ressalvada a obtenção de cópias** para a qual cada procurador poderá retirá-los pelo prazo de 1 hora independentemente de ajuste;

■ **Lei n. 11.965, de 03.07.2009** — dá nova redação aos arts. 982 e 1.124-A do CPC/73, dispondo sobre a participação do **defensor público** na lavratura da escritura pública de inventário e de partilha, de separação consensual e de divórcio consensual;

■ **Lei n. 11.925, de 17.04.2009** — possibilidade de declaração de autenticidade dos documentos em cópia oferecidos para prova pelo próprio advogado e sob sua responsabilidade, além de dispor sobre hipóteses de cabimento dos recursos ordinários para instâncias superiores;

■ **Lei n. 11.900, de 08.01.2009** — altera dispositivos do CPP para prever a possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais por sistema de **videoconferência**, além de dar outras providências;

■ **Lei n. 11.694, de 12.06.2008** — dispõe sobre a responsabilidade civil e a execução de dívidas de Partidos Políticos;

■ **Lei n. 11.672, de 08.05.2008** — estabelece o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STJ, introduzindo o art. 543-C no CPC/73;

■ **Lei n. 11.448, de 15.01.2007** — altera o art. 5.º da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública, legitimando para sua propositura a **Defensoria Pública**. Conforme vimos no *item 12.6.9.10*, o STF, por unanimidade (8 x 0), em 07.05.2015, julgou **improcedente** o pedido formulado na **ADI 3.943**, declarando a **constitucionalidade** da Lei n. 11.448/2007;

■ **Lei n. 11.441, de 04.01.2007** — altera o CPC/73, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela **via administrativa** (“simplificação de procedimentos”);

■ **Lei n. 11.419, de 19.12.2006** — dispõe sobre a *informatização do processo judicial* e altera artigos do CPC/73. A **Resolução n. 427/2010**, com alterações, regulamenta o meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais no STF (e-STF) e dá outras providências;

■ **Lei n. 11.418, de 19.12.2006** — regulamenta o § 3.º do art. 102 da Constituição Federal (**“repercussão geral”**), acrescentando os arts. 543-A e 543-B ao CPC/73;

■ **Lei n. 11.417, de 19.12.2006** — regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de *súmula*

vinculante pelo STF, e dá outras providências;

■ **Lei n. 11.382, de 06.12.2006** — altera dispositivos do CPC/73 relativos ao processo de execução e a outros assuntos;

■ **Lei n. 11.341, de 07.08.2006** — altera o parágrafo único do art. 541 do CPC/73 para admitir as decisões disponíveis em *mídia eletrônica*, inclusive na *Internet*, entre as suscetíveis de prova de divergência jurisprudencial;

■ **Lei n. 11.280, de 16.02.2006** — altera os arts. 112, 114, 154, 219, 253, 305, 322, 338, 489 e 555 do CPC/73 concernentes à incompetência relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por dependência, exceção de incompetência, revelia, carta precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos autos; e revoga o art. 194 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 — Código Civil;

■ **Lei n. 11.277, de 07.02.2006** — acresce o art. 285-A ao CPC/73, buscando a “racionalização do julgamento de processos repetitivos” (cf. *ADI 3.695*, questionando a constitucionalidade da lei);

■ **Lei n. 11.276, de 07.02.2006** — altera os arts. 504, 506, 515 e 518 do CPC/73, relativamente à forma de interposição de recursos, ao saneamento de nulidades processuais, ao recebimento de recurso de apelação e a outras questões. Destaque-se nesta lei o início da discussão sobre a *súmula impeditiva de recursos*, que será ampliada com a aprovação da “PEC Paralela da Reforma do Poder Judiciário”;

■ **Lei n. 11.232, de 22.12.2005** — modifica o CPC/73 para estabelecer a fase de *cumprimento das sentenças* no processo de conhecimento e revogar dispositivos relativos à execução fundada em título judicial, além de outras providências. Dessa forma, as decisões judiciais ganham mais efetividade, tendo em vista a atribuição de carga executiva dentro do processo de conhecimento (cf. **ADI 3.740**, questionando a constitucionalidade do § 1.º do art. 475-L e o parágrafo único do art. 741 do CPC/73, com a redação alterada pela Lei n. 11.232/2005, bem como do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, na redação conferida pela MP n. 2.180-35);

■ **Lei n. 11.187, de 19.10.2005** — modifica o CPC/73 para, conferindo

nova disciplina ao cabimento dos agravos retido e de instrumento, abrir “espaço” para o julgamento dos recursos de apelação (já que o recurso de agravo de instrumento tem prioridade no julgamento), desobstruindo-se a pauta dos Tribunais de Justiça.

■ 14.11. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

■ 14.11.1. Os remédios constitucionais nas Constituições brasileiras — quadro esquematizado

Objetivamos neste item apresentar, esquematicamente, a evolução histórica dos **remédios constitucionais** nas Constituições brasileiras, para, nos itens seguintes, fazermos um estudo de cada um deles.

Dessa maneira, mediante “visualização comparativa”, procuramos facilitar o entendimento histórico de algumas situações, por exemplo, o motivo de ter-se desenvolvido, no Brasil, a “teoria brasileira do *habeas corpus*”, já que à época do texto de 1891 só existia, como remédio, o “HC”.

Para o ilustre leitor, amigo e guerreiro “concurseiro”, sem dúvida, o quadro abaixo mostra-se bastante importante no processo de memorização comparativa, facilitando, assim, o enfrentamento das provas, nas quais, cada vez mais, tem-se percebido esse formato de questão.

REMÉDIO CONSTITUCIONAL	PREVISÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
	■ 1891: art. 72, § 22 ■ EC n. 1/26: restrição à “Teoria Brasileira do HC” ■ 1934: art. 113, n. 23 ■ 1937: art. 122, n. 16

<i>Habeas Corpus</i>	■ 1946: art. 141, § 23 ■ 1967: art. 150, § 20 ■ AI-5, de 13.12.1968: restrição da amplitude do HC ■ EC n. 1/69: art. 153, § 20 ■ 1988: art. 5.º, LXVIII
Mandado de Segurança	■ 1934: art. 113, n. 33 ■ 1937: não houve previsão ■ 1946: art. 141, § 24 ■ 1967: art. 150, § 21 ■ EC n. 1/69: art. 153, § 21 ■ 1988: art. 5.º, LXIX
Mandado de Segurança Coletivo	■ 1988: art. 5.º, LXX
Mandado de Injunção	■ 1988: art. 5.º, LXXI
<i>Habeas Data</i>	■ 1988: art. 5.º, LXXII
Ação Popular	■ 1934: art. 113, n. 38132 ■ 1937: não houve previsão ■ 1946: art. 141, § 38 ■ 1967: art. 150, § 31

	■ EC n. 1/69: art. 153, § 31 ■ 1988: art. 5.º, LXXIII
--	---

■ 14.11.2. *Habeas corpus* (art. 5.º, LXVIII) [132](#)

■ 14.11.2.1. *Regras gerais*

Historicamente, o *habeas corpus* foi a primeira garantia de direitos fundamentais, concedida por “João Sem Terra”, monarca inglês, na Magna Carta, em 1215, e formalizada, posteriormente, pelo *Habeas Corpus Act*, em 1679.

No Brasil, a primeira manifestação do instituto deu-se em 1821, através de um alvará emitido por Dom Pedro I, pelo qual se assegurava a liberdade de locomoção. A terminologia “*habeas corpus*” só apareceria em 1830, no Código Criminal.

Foi garantido constitucionalmente a partir de 1891, permanecendo nas Constituições subsequentes, inclusive na de 1988, que, em seu art. 5.º, LXVIII, estabelece:

“conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua **liberdade de locomoção**, por ilegalidade ou abuso de poder”.

O *habeas corpus* foi inicialmente utilizado como remédio para garantir não só a liberdade física como também os demais direitos que tinham por pressuposto básico a locomoção. Tratava-se da chamada “teoria brasileira do *habeas corpus*”, que perdurou até o advento da Reforma Constitucional de 1926, impondo o exercício da garantia somente para os casos de lesão ou ameaça de lesão à **liberdade de ir e vir**.

O autor da ação constitucional de *habeas corpus* recebe o nome de **impetrante**; o indivíduo em favor do qual se impetra, **paciente** (podendo ser o

próprio impetrante), e a autoridade que pratica a ilegalidade ou abuso de poder, **autoridade coatora** ou **impetrado**.

O impetrante, portanto, poderá ser qualquer pessoa física (nacional ou estrangeira) em sua própria defesa, em favor de terceiro, podendo ser o Ministério Público ou mesmo pessoa jurídica (mas, é claro, em favor de pessoa física). Já o magistrado, na qualidade de Juiz de Direito, no exercício da atividade jurisdicional, a Turma Recursal, o Tribunal poderão **concedê-lo de ofício**, em exceção ao *princípio da inércia do órgão jurisdicional*. Mas **cuidado**: o Juiz de Direito, o Desembargador, os Ministros, quando não estiverem exercendo a atividade jurisdicional, **impetrarão**, e não concederão de ofício, naturalmente, o *habeas corpus*, já que atuando como pessoa comum.

Referida ação pode ser formulada **sem advogado**, não tendo de obedecer a nenhuma formalidade processual ou instrumental, sendo, por força do art. 5.º, LXXVII, **gratuita**.

Pode o HC ser impetrado para trancar ação penal ou inquérito policial, bem como em face de particular, como no clássico exemplo de hospital psiquiátrico que priva o paciente de sua liberdade de ir e vir, ilegalmente, atendendo a pedidos desumanos de filhos ingratos que abandonam seus pais.

■ 14.11.2.2. Esquematização da evolução histórica do “HC” no constitucionalismo brasileiro

DISPOSITIVO	CONTEÚDO/CARACTERÍSTICA
Decreto n. 114, de 23.05.1821	Antes da Constituição de 1824, referido decreto fixava providências para a garantia da liberdade individual, <i>proibindo prisões arbitrárias</i> (Alvará de D. Pedro I).
Constituição de 1824	Não havia previsão expressa da garantia do HC na Constituição do Império de 1824. Muito embora não houvesse previsão expressa da garantia

Constituição de 1824	do HC, a Constituição de 1824 tutelou a liberdade de locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e também <i>vedou</i> qualquer hipótese de <i>prisão arbitrária</i> .
Código Criminal, de 16.12.1830 (arts. 183-188)	Pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro tivemos a previsão expressa da terminologia <i>Habeas Corpus</i> .
Código de Processo Criminal de Primeira Instância (Lei n. 127, de 29.11.1832, arts. 340-345)	Previsão expressa da garantia do HC.
Lei n. 2.033, de 20.09.1871 (art. 18)	Ampliou ao assegurar a impetração de HC também para beneficiar estrangeiros.
Constituição de 1891 (art. 72, § 22)	Pela primeira vez tivemos a constitucionalização do HC: “Dar-se-á o <i>habeas corpus</i> sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder”.
EC n. 1, de 03.09.1926, à CF/1891 (restrição da “Teoria Brasileira do HC”: nova redação ao art. 72, § 22, restringindo o remédio à liberdade de locomoção)	“Dar-se-á o <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção .”
	“Dar-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua

Constituição de 1934 (art. 113, n. 23)	transgressões disciplinares não cabe o <i>habeas corpus</i> . Também restrito à liberdade de locomoção , embora não expressa, já que é na CF/34 que surge, pela primeira vez, o mandado de segurança individual .
Constituição de 1937 (art. 122, n. 16)	“Dar-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e vir , salvo nos casos de punição disciplinar.”
Constituição de 1946 (art. 141, § 23)	“Dar-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção , por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o <i>habeas corpus</i> .”
Constituição de 1967 (art. 150, § 20) (redação idêntica à da CF/46)	“Dar-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção , por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não caberá <i>habeas corpus</i> .”
AI-5, de 13.12.1968 (art. 10) (perdurou até a sua revogação pela EC n. 11, de 17.10.1978)	“Fica suspensa a garantia de <i>habeas corpus</i> , nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.”
EC n. 1/69 (art. 153, § 20) (redação idêntica à da Const./67)	“Dar-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção , por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não caberá <i>habeas corpus</i> .”
Constituição de 1988 (art. 5.º, LXVIII)	“Conceder-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção , por ilegalidade ou abuso de poder.”

	liberdade de locomoção , por ilegalidade ou abuso de poder.”
Constituição de 1988 (art. 142, § 2.º)	“Não caberá <i>habeas corpus</i> em relação a punições disciplinares militares.”

■ 14.11.2.3. Competência

O órgão competente para apreciar a ação de *habeas corpus* será determinado de acordo com a autoridade coatora, e a Constituição prevê algumas situações atribuindo previamente a competência a tribunais, em razão do paciente:

■ **art. 102, I, “d”**: competência originária do **STF** para processar e julgar *habeas corpus*, quando o paciente for qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, quais sejam: *a)* alínea “b” — Presidente da República, Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, Ministros do STF e o Procurador-Geral da República; *b)* alínea “c” [133](#) — Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do TCU e chefes de missão diplomática de caráter permanente;

■ **art. 102, I, “i”**: [134](#) competência originária do **STF** para processar e julgar *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (STF);

■ **art. 102, II, “a”**: compete ao **STF** julgar, em **recurso ordinário**, *habeas corpus* decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

■ **art. 105, I, “c”**: [135](#) competência originária do **STJ** para processar e julgar *habeas corpus*, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, [136](#) ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição do STJ, ou quando o coator for Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

■ **art. 105, II, “a”**: compete ao **STJ** julgar, em **recurso ordinário**, os *habeas corpus* decididos em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for **denegatória**;

■ **art. 108, I, “d”**: compete aos **TRFs** processar e julgar, originariamente, os *habeas corpus*, quando a autoridade coatora for juiz federal;

■ **art. 108, II**: compete aos **TRFs** julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição;

■ **art. 109, VII**: aos **juízes federais** compete processar e julgar os *habeas corpus*, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

■ **art. 121, §§ 3.º e 4.º, V, combinado com o art. 105, I, “c”**: Justiça Eleitoral.

■ **14.11.2.4. Espécies**

O *habeas corpus* será **preventivo** quando alguém se achar **ameaçado** de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (a restrição à locomoção ainda não se consumou). Nessa situação poder-se-á obter um **salvo-conduto** para garantir o livre trânsito de ir e vir.

Quando a constrição ao direito de locomoção já se consumou, estaremos diante do *habeas corpus* **liberatório** ou **repressivo**, para cessar a violência ou coação.

■ **14.11.2.5. Punições disciplinares militares**

O art. 142, § 2.º, estabelece não caber *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares. Trata-se da impossibilidade de se analisar o mérito de

referidas punições, não abrangendo, contudo, os **pressupostos de legalidade** (hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente — HC 70.648, Moreira Alves, e, ainda, RE 338.840-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 19.08.2003).

Essa regra também se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, por força do art. 42, § 1.º, na redação dada pela EC n. 18/98.

■ **14.11.2.6. “Habeas corpus” impetrado em face de ato da “Turma Recursal” — competência do TJ — superada a S. 690/STF**

Conforme vimos no *item 11.6.4* (remetendo o ilustre leitor para a importante discussão lá travada), em se tratando de **Juizados Especiais**, o segundo grau de jurisdição é exercido pelas **Turmas Recursais**, compostas por 3 juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (**Colégio Recursal**) (cf. arts. 41, § 1.º, e 82 da Lei n. 9.099/95).

Mais tecnicamente, poderíamos dizer que as Turmas Recursais funcionam como **segunda instância recursal**, podendo ser enquadradas como **órgãos colegiados de primeiro grau**.

Assim, o STF entendeu **superada** a S. 690, definindo a competência **originária** do **TJ local** para o julgamento de *habeas corpus* contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais (HC 86.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.08.2006, *Inf.* 437/STF).

■ **14.11.3. Mandado de segurança (art. 5.º, LXIX)**

■ **14.11.3.1. Introdução**

O mandado de segurança, criação brasileira, é uma ação constitucional de natureza civil, qualquer que seja a do ato impugnado, seja ele administrativo, seja ele jurisdicional, criminal, eleitoral, trabalhista etc.

Restringido o alcance da “teoria brasileira do *habeas corpus*” pela reforma

constitucional de 1926, sob forte influência da doutrina e jurisprudência da época, que buscavam nas ações possessórias instrumentos para suprir a lacuna deixada pela aludida reforma, o mandado de segurança é constitucionalizado em 1934, sendo introduzido na Carta Maior e permanecendo nas posteriores, com exceção da de 1937. Suas regras gerais foram regulamentadas pela Lei n. 1.533, de 31.12.1951 e outros tantos dispositivos, estando, atualmente, disciplinado na **Lei n. 12.016, de 07.08.2009**, objeto de vários questionamentos nas *ADIs* 4.296 e 4.403 (**matéria pendente**).

Podemos, pois, identificar como fonte imediata de inspiração do mandado de segurança, no direito brasileiro, a “teoria brasileira do *habeas corpus*”, podendo ser destacado, ainda, o art. 13 da Lei n. 221/1894 (ação anulatória de atos da Administração) e o instituto dos interditos possessórios.

Indiretamente, no direito estrangeiro, cumpre mencionar o *habeas corpus* e os *writs* do direito anglo-americano, bem como o *juicio de amparo* do direito mexicano. [137](#)

■ 14.11.3.2. Esquematização da evolução histórica do “MS” no constitucionalismo brasileiro [138](#)

DISPOSITIVO	CONTEÚDO/CARACTERÍSTICA
Constituição de 1934 (art. 113, n. 23)	“Dar-se-á mandado de segurança para defesa do direito, certo e incontestável , ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do <i>habeas corpus</i> , devendo ser sempre ouvida a pessoa de direito público interessada. O mandado não prejudica as ações petições competentes.” (regulamentação pela Lei n. 191, de 16.01.1936)
Constituição de 1937	Não havia previsão expressa da garantia do “MS” na Constituição de 1937 . A doutrina e a jurisprudência, contudo, encontravam na <i>Lei n. 191/36</i> os instrumentos contra os atos ilegais e violadores de direito

	individual.
Constituição de 1946 (art. 141, § 24)	“Para proteger direito líquido e certo não amparado por <i>habeas corpus</i> , conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder .”
Constituição de 1967 (art. 150, § 21)	“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito individual líquido e certo não amparado por <i>habeas corpus</i> , seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder .”
EC n. 1/69 (art. 153, § 21) (redação idêntica à da Const./67)	“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito individual líquido e certo não amparado por <i>habeas corpus</i> , seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder .”
Constituição de 1988 (art. 5.º, LXIX)	“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo , não amparado por <i>habeas corpus</i> ou <i>habeas data</i> , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

■ 14.11.3.3. Abrangência

O constituinte de 1988 assim o definiu: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger **direito líquido e certo**, **não** amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela **ilegalidade ou abuso de poder** for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5.º, LXIX).

Dessa forma, excluindo a proteção de direitos inerentes à **liberdade de locomoção** e ao **acesso ou retificação de informações** relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, através do mandado de segurança busca-

se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder.

■ 14.11.3.4. *Direito líquido e certo*

O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito “manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. [139](#)

Importante lembrar a correção feita pela doutrina em relação à terminologia empregada pela Constituição, na medida em que todo direito, se existente, já é líquido e certo. Os fatos é que deverão ser líquidos e certos para o cabimento do *writ*. [140](#)

■ 14.11.3.5. *Ilegalidade ou abuso de poder*

O cabimento do mandado de segurança dá-se quando perpetrada **ilegalidade ou abuso de poder** por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Quanto a esses dois requisitos pondera Michel Temer, com precisão: “o mandado de segurança é conferido aos indivíduos para que eles se defendam de atos ilegais ou praticados com *abuso de poder*. Portanto, tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários são atacáveis por mandado de segurança, porque a Constituição Federal e a lei ordinária, ao aludirem a *ilegalidade*, estão se referindo ao *ato vinculado*, e ao se referirem a *abuso de poder* estão se reportando ao *ato discricionário*”. [141](#)

■ 14.11.3.6. *Legitimidade ativa e passiva*

O **legitimado ativo, sujeito ativo, impetrante** é o detentor de “direito

líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*”. Assim, dentro do rol “detentor de direito líquido e certo” incluem-se: pessoas físicas (brasileiras ou não, residentes ou não, domiciliadas ou não), jurídicas, órgãos públicos despersonalizados, porém com capacidade processual (Chefias dos Executivos, Mesas do Legislativo), universalidades de bens e direitos (espólio, massa falida, condomínio), agentes políticos (governadores, parlamentares), o Ministério Público etc.

Já o **legitimado passivo, sujeito passivo, impetrado** é a autoridade coatora, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De acordo com o art. 6.º, § 3.º, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Equiparam-se às autoridades os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições (art. 1.º, § 1.º).

A lei deixa claro que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público (art. 1.º, § 2.º).

■ 14.11.3.7. Competência

A **competência** para processar e julgar o mandado de segurança dependerá da categoria da autoridade coatora e sua sede funcional, sendo definida nas leis infraconstitucionais, bem como na própria CF.

No tocante à competência do mandado de segurança contra atos e omissões de tribunais, observa Moraes: “o Supremo Tribunal Federal carece de competência constitucional originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra qualquer ato ou omissão de Tribunal Judiciário, tendo sido o art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman)

inteiramente recepcionado. Por essa razão, a jurisprudência do Supremo é pacífica em reafirmar a competência dos próprios Tribunais para processarem e julgarem os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões”.¹⁴² O mesmo se aplica ao STJ, conforme a Súmula 41. Cf., ainda, a Súmula 624/STF (“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”).

■ 14.11.3.8. *Algumas outras observações*

O mandado de segurança pode ser **repressivo** de ilegalidade ou abuso de poder já praticados, ou **preventivo**, quando estivermos diante de ameaça a violação de direito líquido e certo do impetrante. Muitas vezes, para evitar o perecimento do objeto, o impetrante poderá solicitar concessão de liminar.

Nos termos do art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Nos termos do art. 7.º, § 2.º, da referida lei, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

O prazo para impetração do mandado de segurança, de acordo com o art. 23 da lei, é de **120 dias**, contado da ciência, pelo interessado, do ato a ser impugnado.

Analisando a lei anterior (art. 18 da revogada Lei n. 1.533/51), que também fazia previsão do prazo decadencial de 120 dias, o STF já havia se posicionado, considerando perfeitamente possível o estabelecimento de **prazo decadencial** pela lei do mandado de segurança, mesmo porque o que se opera é a extinção do

prazo para impetrar o *writ*, e não a extinção do próprio direito subjetivo, que poderá ser amparado por qualquer outro meio ordinário de tutela jurisdicional (*vide* STF, RMS 21.362, 14.04.1992, *DJU* de 26.06.1992, e S. 632/STF).

A jurisprudência vem consagrando determinadas posições em relação ao mandado de segurança, tendo sido algumas incorporadas na lei.

Não havendo previsão normativa, ou até contrariando os arts. 267, § 4.º, [143](#) e 269, V, [144](#) do CPC/73, o Pleno do STF, em caso específico, entendeu que “o **impetrante pode desistir de mandado de segurança a qualquer tempo**, mesmo que proferida decisão de mérito a ele favorável, e sem anuência da parte contrária”, mas desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão. Dentre os argumentos está a possibilidade de discussão do direito nas vias ordinárias, além de se ter a segurança de se coibir a má-fé com os instrumentos próprios.

Outro fundamento a confirmar a possibilidade de desistência de mandado de segurança após decisão de mérito foi o reconhecimento de que o *writ*, “enquanto ação constitucional, com base em alegado direito líquido e certo frente a ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se revestiria de lide, em sentido material” (**RE 669.367**, Rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, j. 02.05.2013, Pleno, *DJE* de 30.10.2014).

■ 14.11.4. Mandado de segurança coletivo (art. 5.º, LXX)

■ 14.11.4.1. Regras gerais

A grande diferença entre o mandado de segurança individual e o coletivo (este criado pela CF/88) reside em seu **objeto** e na **legitimação ativa**. As ponderações sobre “direito líquido e certo”, “ilegalidade e abuso de poder”, “legitimação passiva”, “campo residual”, já analisadas quando tratamos do mandado de segurança individual, deverão ser aqui adotadas no estudo do mandado de segurança coletivo. Passemos, então, às regras específicas sobre o objeto (coletivo *lato sensu*) e sobre a legitimação ativa, que, como veremos,

operar-se-á por substituição processual.

■ 14.11.4.2. **Objeto, legitimidade ativa e objetivos**

■ 14.11.4.2.1. **Objeto**

Com o mandado de segurança coletivo, visa-se a proteção de direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data* (campo residual), contra atos ou omissões ilegais ou com abuso de poder de autoridade, buscando a preservação (preventivo) ou reparação (repressivo) de interesses transindividuais, sejam os **individuais homogêneos**, sejam **coletivos**.

O art. 21, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009, na linha do que já conceituava o CDC, define:

■ **individuais homogêneos**: assim entendidos, para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade, ou de parte dos associados ou membros do impetrante;

■ **coletivos**: assim entendidos, para efeito desta lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica.

■ 14.11.4.2.2. **Legitimidade ativa**

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por (art. 5.º, LXX):

■ partido político com representação no Congresso Nacional;

■ organização sindical, entidade de classe ou associação, desde que estejam legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. [145](#)

■ 14.11.4.2.2.1. **Partidos políticos**

No tocante aos **partidos políticos**, bastará a existência de um único parlamentar na Câmara ou Senado, filiado ao partido, para que se configure a “representação no Congresso Nacional”.

A questão discutida é: os partidos políticos poderão representar somente seus filiados e na defesa de, apenas, direitos políticos? Entendemos que não, podendo defender qualquer direito inerente à sociedade, pela própria natureza do direito de representação previsto no art. 1.º, parágrafo único.

CUIDADO: essa, todavia, não é a orientação adotada pelo STJ,¹⁴⁶ em nosso entender, *data venia*, restritiva do previsto na CF, burlando o objetivo maior de defesa da sociedade, já que o constituinte originário não previu outra limitação à atuação dos partidos políticos a não ser a representação no Congresso Nacional. Conforme estabelece o art. 21 da Lei n. 12.016/2009 o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por **partido político** com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos:

- **a seus integrantes; ou**
- **à finalidade partidária.**

■ **14.11.4.2.2.2. Organizações sindicais, entidades de classe e associações**

Já as **organizações sindicais**, **entidades de classe** e **associações** deverão preencher os seguintes requisitos constitucionais:

- estar legalmente constituídas;
- atuar na defesa dos interesses dos seus membros ou associados.

O requisito de **estarem em funcionamento há pelo menos 1 ano** é **exclusivo** das **associações**, não sendo exigida referida pré-constituição anual para os partidos políticos, organizações sindicais e entidades de classe.

“Tratando-se de mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato, é indevida a exigência de um ano de constituição e funcionamento, porquanto **esta**

restrição destina-se apenas às associações, nos termos do art. 5.º, LXX, ‘b’, *in fine*, da CF...” (RE 198.919-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, 15.06.1999, *Inf. 154/STF*).

Acompanhando jurisprudência do STF, entendemos que não há necessidade de autorização específica dos membros ou associados, desde que **haja previsão expressa no estatuto social**.

Ao se referir à defesa dos interesses dos membros ou associados, a Constituição determinou a necessária existência de **pertinência temática** do objeto da ação coletiva com os objetivos institucionais do sindicato, entidade de classe ou associação.

Cuida-se de verdadeira **substituição processual** (legitimação extraordinária) das entidades representando direitos alheios de seus associados.

Por fim, tendo em vista a relevância da matéria, destaca-se (*Inf. 431/STF*): “concluído julgamento de uma série de recursos extraordinários nos quais se discutia sobre o âmbito de incidência do inciso III do art. 8.º da CF/88 (‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas’) (...), conheceu dos recursos e lhes deu provimento para reconhecer que o referido dispositivo assegura **ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das categorias que representam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes**” (RE 193.503/SP, RE 193.579/SP, RE 208.983/SC, RE 210.029/RS, RE 211.874/RS, RE 213.111/SP, RE 214.668/ES, Rel. orig. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, 12.06.2006).

■ 14.11.4.2.3. **Objetivos**

Os dois objetivos buscados com a criação do mandado de segurança coletivo, no entender de Michel Temer, são: [147](#)

- fortalecimento das organizações classistas;

■ “pacificar as relações sociais pela solução que o Judiciário dará a situações controvertidas que poderiam gerar milhares de litígios com a consequente desestabilização da ordem social”.

■ 14.11.5. Mandado de injunção (art. 5.º, LXXI)

■ 14.11.5.1. Aspectos gerais

A Constituição dispõe que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Trata-se, assim como o mandado de segurança coletivo e o *habeas data*, de remédio constitucional **introduzido** pelo **constituente originário de 1988**.

Os dois requisitos constitucionais para o mandado de injunção são:

■ norma constitucional de **eficácia limitada**, prescrevendo **direitos, liberdades constitucionais** e **prerrogativas** inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

■ falta de norma regulamentadora, tornando inviável o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas acima mencionados (omissão do Poder Público).

Dessa forma, tal como a *ADO* — *ação direta de inconstitucionalidade por omissão* (já estudada no item 6.7.4), o mandado de injunção surge para “curar” uma “doença” denominada **síndrome de inefetividade das normas constitucionais**, vale dizer, normas constitucionais que, de imediato, no momento que a Constituição entra em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de ato normativo integrativo e infraconstitucional.

São, portanto, de *aplicabilidade mediata e reduzida*, dividindo-se em dois

grandes grupos: a) *normas de eficácia limitada, declaratórias de princípios institutivos ou organizativos*: normalmente criam órgãos (arts. 91, 125, § 3.º, 131...); b) *normas declaratórias de princípios programáticos*: veiculam programas a serem implementados pelo Estado (ex.: arts. 196, 215, 218, *caput*...).

Dentre as várias distinções, Dirley da Cunha Júnior, em importante monografia sobre o tema das omissões do Poder Público, observa que “o mandado de injunção foi concebido como instrumento de controle concreto ou incidental de constitucionalidade da omissão, voltado à tutela de direitos subjetivos. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi ideada como instrumento de controle abstrato ou principal de constitucionalidade da omissão, empenhado na defesa objetiva da Constituição. Isso significa que o mandado de injunção é uma ação constitucional de *garantia individual*, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação constitucional de *garantia da Constituição*”. [148](#)

■ 14.11.5.2. *Legitimidade ativa e passiva*

Qualquer pessoa poderá impetrar o mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

O STF, inclusive, admitiu o ajuizamento de **mandado de injunção coletivo**, sendo legitimadas, por analogia, as mesmas entidades do mandado de segurança coletivo. O requisito será a falta de norma regulamentadora que torne inviáveis os direitos, liberdades ou prerrogativas dos membros ou associados (indistintamente). [149](#)

E pessoa jurídica de direito público pode impetrar o MI?

Trata-se de situação distinta daquela do *MI coletivo*. Nesta hipótese, a pessoa jurídica de direito público impetraria o MI em seu nome próprio e tendo por fundamento a falta de norma da Constituição que inviabilize, para a entidade de direito público, o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas inerentes à

nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Embora exista decisão não admitindo a legitimação ativa da pessoa jurídica de direito público para a impetração do MI (MI 537/SC, *DJ* de 11.09.2001), o STF parece ter superado esse entendimento anterior, nos termos do [MI 725](#).

No caso concreto, entendeu o STF, nos termos do voto do relator, Min. Gilmar Mendes, tendo por fundamento o “recurso de amparo” do direito ibero-americano, que “não se deve negar aos municípios, peremptoriamente, a titularidade de direitos fundamentais (...) e a eventual possibilidade das ações constitucionais cabíveis para a sua proteção”. Assim, destacando que as pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de direitos fundamentais, “parece bastante razoável a hipótese em que o município, diante de omissão legislativa inconstitucional impeditiva do exercício desse direito, se veja compelido a impetrar mandado de injunção” (cf. *Inf. 466/STF* — j. 10.05.2007, *DJ* de 28.05.2007).

No tocante ao **polo passivo** da ação, somente a pessoa estatal poderá ser demandada e nunca o particular (que não tem o dever de regulamentar a CF). Ou seja, os entes estatais é que devem regulamentar as normas constitucionais de eficácia limitada, como o Congresso Nacional.

■ 14.11.5.3. Competência

A competência vem prevista nos arts.: 102, I, “q”, 102, II, “a”, 105, I, “h”, 121, § 4.º, V, e 125, § 1.º:

■ **102, I, “q”**: compete ao **STF**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio STF;

■ **102, II, “a”**: compete ao **STF** processar e julgar em **recurso ordinário**

o mandado de injunção decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

■ **105, I, “h”**: compete ao **STJ** processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

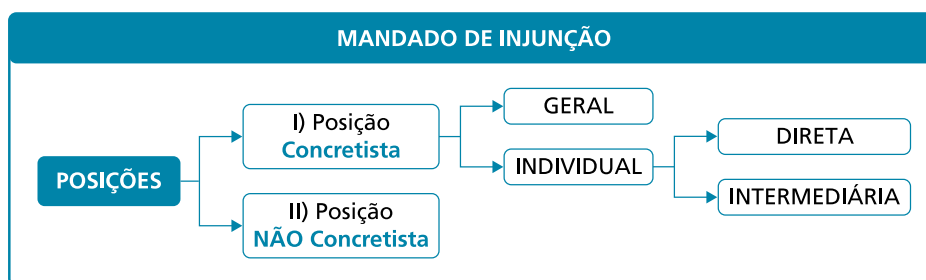
■ **121, § 4.º, V**: competência atribuída ao **TSE** para julgar em grau de recurso mandado de injunção denegado pelo TRE;

■ **125, § 1.º**: estabelece que os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na CF, sendo a competência dos tribunais definida na **Constituição do Estado**. Para se ter um exemplo, no Estado de São Paulo, o julgamento de mandado de injunção contra atos omissivos de autoridades estaduais e municipais é da competência originária do TJ (art. 74, V, da CE/SP — *vide RJTJSP* 176/92).

■ **14.11.5.4. Procedimento e efeitos da decisão**

O mandado de injunção, previsto constitucionalmente, já decidiu o STF, é autoaplicável, sendo adotadas, analogicamente e no que couber, enquanto não editada a legislação específica, as normas do **mandado de segurança** (parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.038/90).

No que respeita aos efeitos da decisão, tanto a doutrina como a jurisprudência são controvertidas, destacando-se os seguintes posicionamentos:



■ **posição concretista geral**: por meio de normatividade geral, o STF

supre a omissão de caráter normativo, produzindo a decisão efeitos *erga omnes* até que sobrevenha norma integrativa pelo órgão omissor;

■ **posição concretista individual direta:** a decisão, implementando o direito, valerá somente para o autor do mandado de injunção, diretamente;

■ **posição concretista individual intermediária:** julgando procedente o mandado de injunção, o judiciário fixa ao órgão omissor prazo para elaborar a norma regulamentadora. Findo o prazo e permanecendo a inércia, o autor passa a ter assegurado o seu direito;

■ **posição não concretista:** a decisão apenas decreta a mora do poder omissor, reconhecendo-se formalmente a sua inércia.

A posição **não concretista**, por muito tempo, foi a dominante no STF (*vide* MI 107-DF).

Esse posicionamento sofreu as nossas críticas, na medida em que se tornaria inviável o exercício de direitos fundamentais, na persistência da inércia normativa. A providência jurisdicional, nesses termos, mostrava-se **inócua**.

Avançando, o STF adotou em alguns casos a **posição concretista individual intermediária**, que corresponde à do Ministro Néri da Silveira, qual seja, fixar um prazo e comunicar ao órgão omissor para que elabore a norma naquele período. Decorrido *in albis* o prazo fixado, o autor passaria a ter o direito pleiteado (efeitos *inter partes*). (*Vide* MI 232-1-RJ, RDA 188/155.)

Dependendo da situação, contudo, já alertávamos em edições anteriores que, se transcorrido período de tempo desarrazoado para que o órgão omissor suprisse o *silêncio legislativo*, o STF já poderia, mesmo sem conceder prazo, de imediato regulamentar o direito violado.

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto proferido no **MI 721/DF**, o qual pretendia fosse suprida a inércia em relação ao art. 40, § 4.º, a fim de viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial, “... salientando o caráter **mandamental** e não simplesmente declaratório do mandado de injunção, asseverou que **cabe** ao Judiciário, por força do disposto no art. 5.º, LXXI e seu § 1.º, da CF, não apenas emitir certidão de omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes à

nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas **viabilizar, no caso concreto, o exercício desse direito, afastando as consequências da inércia do legislador**. Após, pediu vista dos autos o Min. Eros Grau” (MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.09.2006, *Inf.* 445/STF).

Em 30.08.2007, por unanimidade, o Pleno do STF acompanhou o voto do Ministro relator, Marco Aurélio, para deferir ao impetrante o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre planos de benefícios da Previdência Social. [150](#)

No julgamento do **MI 695/MA**, que questionava a mora do Legislativo em regulamentar o art. 7.º, XXI, da CF/88 (*aviso prévio proporcional*), o STF reconheceu que, “... não fosse o pedido da inicial, limitado a requerer a comunicação ao órgão competente para a imediata regulamentação da norma, seria talvez a **oportunidade de reexaminar a posição do Supremo em relação à natureza e à eficácia do mandado de injunção, nos termos do que vem sendo decidido no MI 670/ES**” (v. *Inf.* 430/STF e MI 695/MA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 1.º.03.2007, *Inf.* 457/STF).

Em momento seguinte, **evoluindo**, o STF retomou o julgamento da matéria, apreciando novos mandados de injunção.

Conforme já expusemos no *item 3.7.2.1* — e vale resgatar o tema —, o art. 7.º, XXI, da CF/88, foi classificado pela doutrina como norma constitucional de **eficácia limitada** e, por isso, o cabimento do mandado de injunção.

Referido direito fundamental veio a ser regulamentado mais de 20 anos após a promulgação da CF/88, nos termos da **Lei n. 12.506, de 11.10.2011**. [151](#)

O STF, no julgamento desses novos MIs, *antes do advento da norma*, julgou procedente o pedido para reconhecer a mora e **garantir a concretização** do direito previsto na Constituição e para o caso concreto (**MI 943, 1.010, 1.074 e 1.090**, j. 22.06.2011).

Diante de indecisão sobre qual parâmetro adotar (e, assim, estabelecer o efeito **aditivo**), até porque não havia nenhum critério normativo preestabelecido a ser observado, houve suspensão do julgamento.

Em seguida, com censurável atraso, o Congresso Nacional aprovou a citada

Lei n. 12.506/2011, que não retroagiu e, assim, não resolveu a situação dos trabalhadores demitidos antes de sua vigência e que *ajuizaram mandado de injunção, pendente de julgamento*.

O STF, então, resolvendo a questão, determinou a utilização dos critérios e padrões normativos estabelecidos na referida lei (**sentença aditiva**, portanto), adotando, como anotou o Min. Gilmar Mendes, um “posicionamento menos invasivo às competências do Congresso Nacional e perfeitamente cabível para o deslinde das ações mandamentais” (fls. 47 do acórdão, j. 06.02.2013). [152](#)

Por fim, destacamos o julgamento dos **MIIs 670, 708 e 712**, ajuizados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais Cíveis do Estado do Espírito Santo (Sindpol), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa (Sintem) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Sinjep), buscando assegurar o direito de greve para seus filiados, tendo em vista a inexistência de lei regulamentando o art. 37, VII, da CF/88.

O STF, em importante decisão, por unanimidade, declarou a omissão legislativa e, por maioria, determinou a aplicação, no que couber, da lei de greve vigente no setor privado, Lei n. 7.783/89.

A aplicação da lei não se restringiu aos impetrantes, mas a todo o funcionalismo público (sobre o exercício do direito de greve pelos **policiais civis, não reconhecido** pelo STF, cf. *item 13.7.9*). Assim, pode-se afirmar que o STF consagrou, em referido julgamento e de modo excepcional, a **teoria concretista geral**. [153](#)

Dessa forma, o STF, especialmente diante da regra contida no art. 5.º, § 1.º, que preceitua terem as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais **aplicação imediata**, vem regulando provisoriamente o tema, até que o órgão omissor normatize a matéria, concretizando, assim, os direitos fundamentais.

Conforme anotou Gilmar Mendes, “o Tribunal adotou, portanto, uma moderada *sentença de perfil aditivo*, introduzindo modificação substancial na técnica de decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão”. [154](#)

■ 14.11.5.5. *Perspectivas de um “ativismo judicial”*

Por todo o exposto, parece-nos que, diante da **inércia** não razoável do órgão que deveria normatizar a matéria, o Judiciário, em uma **postura ativista**, passa a ter elementos para suprir a omissão, como se verificou nos vários exemplos, fazendo com que o direito fundamental possa ser realizado.

Não se pode admitir que temas tão importantes como o direito de greve dos servidores públicos, por exemplo, possam ficar sem regulamentação por mais de 20 anos. O Judiciário, ao agir, **realiza direitos fundamentais**, e, nesse sentido, as técnicas de controle das omissões passam a ter efetividade.

Naturalmente, saindo da inércia, o futuro ato normativo a ser editado deverá ser aplicado, podendo, é claro, vir a ser questionado no Judiciário.

Essa é a nova perspectiva. Não se incentiva um Judiciário a funcionar como “legislador” positivo no caso da existência de ato normativo a suprir a omissão, mas, havendo a sua falta e sendo a inércia **desarrazoada, negligente e desidiosa**, dentro dos limites das técnicas de controle das omissões, busca-se a efetivação dos direitos fundamentais, seja pelo mandado de injunção (MI), seja pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO).

■ 14.11.6. *Habeas data* (art. 5.º, LXXII)

■ 14.11.6.1. *Aspectos gerais*

Introduzido pela CF/88, conceder-se-á ***habeas data***:

- para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

A garantia constitucional do *habeas data*, regulamentada pela Lei n. 9.507, de

12.11.1997, destina-se a disciplinar o direito de acesso a informações, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para **conhecimento ou retificação** (tanto informações erradas como imprecisas, ou, apesar de corretas e verdadeiras, desatualizadas), todas referentes a **dados pessoais**, concernentes à **pessoa do impetrante**. [155](#)

Essa garantia não se confunde com o direito de obter certidões (art. 5.º, XXXIV, “b”), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5.º, XXXIII). Havendo recusa no fornecimento de certidões (para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), ou informações de terceiros, o remédio próprio é o **mandado de segurança**, e não o *habeas data*. Se o pedido for para assegurar o conhecimento de informações relativas à **pessoa do impetrante**, aí sim o remédio será o *habeas data*.

A sutileza da primeira distinção foi muito bem apreendida por Michel Temer: “O *habeas data* também não pode ser confundido com o direito à obtenção de certidões em repartições públicas. Ao pleitear certidão, o solicitante deve demonstrar que o faz para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (art. 5.º, XXXIV, ‘b’). No *habeas data* basta o simples desejo de conhecer as informações relativas à sua pessoa, independentemente da demonstração de que elas se prestarão à defesa de direitos”. [156](#)

■ 14.11.6.2. **Legitimidade ativa e passiva**

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá ajuizar a ação constitucional de *habeas data* para ter acesso às informações a seu respeito.

O **polo passivo** será preenchido de acordo com a natureza jurídica do banco de dados. Em se tratando de registro ou banco de dados de **entidade governamental**, o sujeito passivo será a pessoa jurídica componente da administração direta e indireta do Estado. Na hipótese de registro ou banco de dados de **entidade de caráter público**, a entidade que não é governamental, mas, de fato, privada, figurará no polo passivo da ação.

O art. 1.º, parágrafo único, da Lei n. 9.507/97 considera de caráter público “todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”.

Assim, perfeitamente possível enquadrarmos as empresas privadas de serviço de proteção ao crédito (SPC) no polo passivo na ação de *habeas data*. Aliás, o art. 43, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) estabelece que “os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados **entidades de caráter público**”.

■ 14.11.6.3. *Procedimento*

Acompanhando posição do antigo TFR (HD 7-DF, 16.03.1989, *DJU* de 15.05.1989), do STJ (materializada em sua Súmula 2), bem como do STF (RHD 22-8-DF), o art. 8.º da lei regulamentadora exige prova da recusa de informações pela autoridade, sob pena de, inexistindo pretensão resistida, a parte ser julgada carecedora da ação, por falta de interesse processual. [157](#)

O art. 21 da lei do *habeas data*, em cumprimento ao dispositivo constitucional constante do art. 5.º, LXXVII, previu serem **gratuitos** o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotações de justificação, bem como a ação de *habeas data*.

■ 14.11.6.4. *Competência*

As regras sobre competência estão previstas na Constituição e no art. 20 da Lei n. 9.507/97:

■ **art. 102, I, “d”**: competência originária do **STF** para processar e julgar o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF;

■ **art. 102, II, “a”**: compete ao **STF** julgar em recurso ordinário o *habeas data* decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

■ **art. 105, I, “b”**:[158](#) compete ao **STJ** processar e julgar, originariamente, os *habeas data*, contra ato do Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou do próprio tribunal;

■ **art. 108, I, “c”**: competência originária dos **TRFs** para processar e julgar os *habeas data* contra ato do próprio tribunal ou do juiz federal;

■ **art. 109, VIII**: aos **juízes federais** compete processar e julgar os *habeas data* contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

■ **art. 121, § 4.º, V**: competência atribuída ao **TSE** para julgar em grau de recurso *habeas data* denegado pelo TRE;

■ **art. 125, § 1.º**: em relação aos Estados a competência será definida pela **Constituição Estadual** (art. 74, III, da CE/SP).

■ **14.11.7. Ação popular (art. 5.º, LXXIII)**

■ **14.11.7.1. Aspectos gerais**

Não obstante a Constituição de 1824 falasse em ação popular (art. 157),[159](#) parece que esta se referia a certo caráter disciplinar ou mesmo penal. Desse modo, concordamos com Mancuso, ao sustentar que a Constituição de 1934 foi “o primeiro texto constitucional que lhe deu guarida”.[160](#)

Elevada ao nível constitucional em **1934**, retirada da Constituição de 1937, retornou na de 1946 e permanece até os dias atuais, prevista no art. 5.º, LXXIII, da CF/88:[161](#)

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Assim como o voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, a **ação popular**, corroborando o preceituado no art. 1.º, parágrafo único, da CF/88, constitui importante instrumento da democracia direta e participação política. Busca-se a proteção da *res publica*, ou, utilizando uma nomenclatura mais atualizada, tem por escopo a proteção dos interesses difusos. [162](#)

■ 14.11.7.2. Esquematização da evolução histórica da “ação popular” no constitucionalismo brasileiro

DISPOSITIVO	CONTEÚDO/CARACTERÍSTICA
Constituição de 1934 (art. 113, n. 38)	“Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios.”
Constituição de 1937	Não houve previsão expressa da ação popular.
Constituição de 1946 (art. 141, § 38)	“Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.”
Constituição de 1967 (art. 150, § 31)	“Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas.”
EC n. 1/69 (art. 153, § 21)	“Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que

(redação idêntica à da Const./67)	“Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas.”
Constituição de 1988 (art. 5.º, LXXIII) (ampliação de seu objeto)	“Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. ” (cf. <i>Lei n. 4.717, de 29.06.1965</i>)

■ 14.11.7.3. Requisitos

Deve haver **lesividade**:

- ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (entendam-se entidades da administração direta, indireta, incluindo portanto as entidades paraestatais, como as empresas públicas, sociedades de economia mista..., bem como toda pessoa jurídica subvencionada com dinheiro público); [163](#)
- à moralidade administrativa;
- ao meio ambiente;
- ao patrimônio histórico e cultural.

Por lesividade deve-se entender, também, ilegalidade, pois, como assinalou Temer, “embora o texto constitucional não aluda à ilegalidade, ela está sempre presente nos casos de lesividade ao patrimônio público”. [164](#)

Apesar dessa constatação no que tange ao **patrimônio público**, resta indagar se o binômio **lesividade/ilegalidade** deve sempre estar presente como requisito para a propositura da ação popular. Embora reconheça dificuldade, José Afonso da Silva observa: “na medida em que a Constituição amplia o âmbito da ação popular, a tendência é a de erigir a lesão, em si, à condição de motivo autônomo

evidente em relação à **moralidade administrativa**, na medida em que não é meramente subjetiva nem puramente formal, tendo “... conteúdo jurídico a partir de regras e princípios da Administração”. [165](#)

Nesse sentido, Mancuso defende que a Constituição erigiu a **moralidade administrativa** a **fundamento autônomo** para a propositura da ação popular. Em suas palavras, “... se a causa da ação popular for um ato que o autor reputa ofensivo à moralidade administrativa, sem outra conotação de palpável lesão ao erário, cremos que em princípio a ação poderá vir a ser acolhida, em restando provada tal pretensão...”. [166](#)

Outro requisito, como veremos, diz respeito à legitimidade ativa, que pertence apenas ao **cidadão**.

■ 14.11.7.4. *Legitimidade ativa e passiva*

Somente poderá ser autor da ação popular o **cidadão**, assim considerado o brasileiro nato ou naturalizado, desde que esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, provada tal situação (e como requisito essencial da inicial) pelo título de eleitor, ou documento que a ele corresponda (art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65).

Assim, excluem-se do polo ativo os estrangeiros, os apátridas, as pessoas jurídicas (*vide* Súmula 365 do STF) e mesmo os brasileiros que estiverem com os seus direitos políticos suspensos ou perdidos (art. 15 da CF/88).

Entendemos que aquele entre 16 e 18 anos de idade, que tem título de eleitor, pode ajuizar a ação popular sem a necessidade de assistência, porém, **sempre por advogado** (capacidade postulatória). Nesse sentido:

“A Constituição da República estabeleceu que o *acesso à justiça* e o *direito de petição* são direitos fundamentais (art. 5.º, XXXIV, ‘a’, e XXXV), porém estes não garantem a quem não tenha capacidade postulatória litigar em juízo, ou seja, é **vedado o exercício do direito de ação sem a presença de um advogado**, considerado ‘indispensável à administração da justiça’ (art. 133 da Constituição da República e art. 1.º da Lei n. 8.906/94), com as **ressalvas**

legais. (...) Incluem-se, ainda, no rol das exceções, as ações protocoladas nos juizados especiais cíveis, nas causas de valor até vinte salários mínimos (art. 9.º da Lei n. 9.099/95) e as ações trabalhistas (art. 791 da CLT), **não fazendo parte dessa situação privilegiada a ação popular**” (AO 1.531-AgR, voto da Min. Cármen Lúcia, j. 03.06.2009, Plenário, *DJE* de 1.º.07.2009).

Teoricamente, se houver reciprocidade (art. 12, § 1.º), o português poderá ajuizar a ação popular. Na prática, contudo, como existe vedação da Constituição de Portugal, não seria possível, pois não há como estabelecer a reciprocidade.

No **polo passivo**, de acordo com o art. 6.º da lei, que é extremamente minucioso, figurarão o agente que praticou o ato, a entidade lesada e os beneficiários do ato ou contrato lesivo ao patrimônio público.

O art. 6.º, § 3.º, da lei permite que a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, abstenha-se de contestar o pedido ou atue ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

O Ministério Público, **parte pública autônoma**, funciona como fiscal da lei (de modo mais abrangente, o art. 179, *caput*, do CPC/2015, fala em “fiscal da **ordem jurídica**”), mas se o autor popular desistir da ação poderá (entendendo presentes os requisitos) promover o seu prosseguimento (art. 9.º da lei).

■ 14.11.7.5. Competência

■ 14.11.7.5.1. Regra geral — juízo de primeiro grau

As regras de competência dependerão da origem do ato ou omissão a serem impugnados. Para exemplificar, se o patrimônio lesado for da União, competente será a Justiça Federal (*vide* art. 5.º da lei), e assim por diante.

Cabe alertar que “a competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, **em regra**, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. Julgado o feito na primeira

instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra ‘n’ do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal” (AO 859-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* de 1.º.08.2003).

Assim, pode ser que, fugindo à regra geral da competência do juízo de primeiro grau, caracterize-se a competência **originária** do **STF** para o julgamento da ação popular, como nas hipóteses das alíneas “f” [167](#) e “n” [168](#) do art. 102, I, da CF/88, quais sejam, respectivamente:

- as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
- a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.

■ **14.11.7.5.2. SEBRAE — competência da Justiça comum**

Segundo compilado no *Inf. 447/STF*, “competete à Justiça Comum o julgamento de causas que envolvam o SEBRAE”, e não à Justiça Federal. Isso porque “... entendeu-se que o referido ente não corresponde à noção constitucional de autarquia, a qual deve ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito privado, como no caso. Ademais, asseverou-se que o disposto no art. 20, ‘c’, da mencionada Lei 4.717/65 não transformou em autarquia as entidades de direito privado que recebem e aplicam contribuições parafiscais, mas apenas as incluiu no rol de proteção da ação popular. Precedente citado: RE 336.168/SC (*DJU* de 14.05.2004)” (**RE 414.375/SC**, Rel. Min. Gilmar Mendes, 31.10.2006).

■ **14.11.7.5.3. Ação popular contra o CNMP — incompetência do STF**

■ 14.11.7.5.3. *Ação popular contra o CNMP — incompetência do STF*

O STF “... não conheceu de ação popular ajuizada por advogado contra o Conselho Nacional do Ministério Público — CNMP, na qual se pretendia a nulidade de decisão, por esta proferida pela maioria de seus membros, que prorrogara o prazo concedido, pela Resolução 5/2006, aos membros do Ministério Público ocupantes de outro cargo público, para que estes retornassem aos órgãos de origem. Entendeu-se que a alínea ‘r’, do inciso I, do art. 102 da CF (‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal... I — processar e julgar, originariamente:... r) as ações contra o... Conselho Nacional do Ministério Público;’), introduzida pela EC 45/2004, refere-se a ações contra os respectivos colegiados e não aquelas em que se questiona a responsabilidade pessoal de um ou mais conselheiros, caso da ação popular. Salientou-se, tendo em conta o que disposto no art. 6.º, § 3.º, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que o CNMP, por não ser pessoa jurídica, mas órgão colegiado da União, nem estaria legitimado a integrar o polo passivo da relação processual da ação popular. Asseverou-se, no ponto, que, ainda que se considerasse a menção ao CNMP como válida à propositura da demanda contra a União, seria imprescindível o litisconsórcio passivo de todas as pessoas físicas que, no exercício de suas funções no colegiado, tivessem concorrido para a prática do ato, ou seja, os membros que compuseram a maioria dos votos da decisão impugnada. Por fim, ressaltando a jurisprudência da Corte no sentido de, tratando-se de ação popular, admitir sua competência originária somente no caso de incidência da alínea ‘n’ do inciso I do art. 102, da CF ou de a lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro, concluiu-se que, mesmo que emendada a petição inicial no tocante aos sujeitos passivos da lide e do pedido, não seria o caso de competência originária” (Pet. 3.674 QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04.10.2006, *Inf.* 443/STF).

■ 14.11.7.5.4. *Incompetência originária do STF e indicação do órgão competente*

juízo competente.

Como se sabe, o STF reconheceu o **princípio da reserva constitucional de competência originária**, e, assim, toda a atribuição do STF está explicitada, taxativamente, no art. 102, I, da CF/88, pedindo-se vênica para transcrever o importante precedente:

“A competência do STF — cujos fundamentos repousam na Constituição da República — submete-se a **regime de direito estrito**. A competência originária do STF, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional — e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida — não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em *numerus clausus*, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o STF, por efeito da **taxatividade do rol constante da Carta Política**, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, *b* e *c*), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, *d*). Precedentes” (Pet. 1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.09.1999, DJ de 1.º.10.1999).

Partindo dessa premissa, resta analisar se o STF deve ou não indicar o órgão que repute competente, na hipótese de não reconhecer a sua competência originária.

Após longa discussão, com argumentos interessantes trazidos pelo Min. Lewandowski, o STF entendeu, nos termos do art. 113, § 2.º, do CPC/73 e do art. 21, § 1.º, do *RISTF*, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, que é atribuição do STF **indicar o órgão que repute competente** para o julgamento do feito ajuizado originariamente, atribuição essa autorizada,

inclusive, ao Relator monocraticamente (cf. Pet. 3.986 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.6.2008, *Inf.* 512/STF).

■ 14.11.7.6. Outras regras

Desde que presentes os requisitos legais (*periculum in mora* e *fumus boni iuris*), é possível a concessão de liminar, podendo a ação popular ser tanto **preventiva**, visando evitar atos lesivos, como **repressiva**, buscando o ressarcimento do dano, a anulação do ato, a recomposição do patrimônio público lesado, indenização etc.

A coisa julgada se opera *secundum eventum litis*, ou seja, se a ação for julgada **procedente ou improcedente por ser infundada**, produzirá efeito de coisa julgada oponível *erga omnes*. No entanto, se a improcedência se der por deficiência de provas, haverá apenas a coisa julgada formal, podendo qualquer cidadão intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (art. 18 da lei), já que não terá sido analisado o mérito.

Julgada improcedente a ação (pelo art. 267 ou 269 do CPC/73 — com correspondência nos arts. 485 e 487 do CPC/2015), só produzirá efeitos depois de passar pelo duplo grau obrigatório de jurisdição. Julgada procedente, a apelação será recebida no seu duplo efeito: devolutivo e suspensivo (art. 19 da lei).

O autor da ação popular é isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.

■ 14.12. QUESTÕES

■ 14.12.1. Direitos fundamentais

1. (OAB/100.º) Direitos e suas garantias: os direitos são bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer esses direitos, são instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e gozo

daqueles bens e vantagens. Assinale a alternativa em que não se verifica a correspondência entre o direito e sua garantia:

- a) todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza — art. 5.º (direito). A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei — art. 5.º, XLII (garantia);
- b) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato — art. 5.º, IV (direito). É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem — art. 5.º, V (garantia);
- c) é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz — art. 5.º, XV (direito). Conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder — art. 5.º, LXVIII (garantia);
- d) é plena a liberdade de associação — art. 5.º, XVII (direito). Conceder-se-á *habeas data* — art. 5.º, LXXII (garantia).

2. (MP/80.º) Pode ser extraditado o brasileiro naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Esta afirmativa:

- a) mostra-se incompleta, porque não só o brasileiro naturalizado como também o nato pode ser extraditado;
- b) mostra-se compatível com o que dispõe a CF, no capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
- c) mostra-se incompatível com esse mesmo capítulo;
- d) mostra-se incorreta, porque importa o momento da prática do crime comum, se antes ou após a naturalização;
- e) mostra-se incorreta, porque a prática de crime comum não autoriza a extradição.

3. (Magistratura/169.º) As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, são asseguradas aos litigantes nos processos:

- a) judiciais cíveis e criminais;
- b) judiciais e administrativos;
- c) judiciais de natureza criminal;
- d) judiciais e administrativos que tenham por objeto a demissão de servidor público.

- c) judiciais de natureza criminal;
- d) judiciais e administrativos que tenham por objeto a demissão de servidor público.

4. (Magistratura/171.º) Constitui embaraço à plena liberdade de informação dos meios de comunicação:

- a) o exercício do direito de resposta, proporcional ao agravo;
- b) o ressarcimento pelos danos morais causados por informação que violou a vida privada;
- c) dispositivo de lei ordinária que obrigue a revelação da fonte das informações veiculadas por jornalistas;
- d) condenação judicial de jornalista que, em matéria assinada, pratica o crime de calúnia contra alguém.

5. (Magistratura/172.º) A casa é asilo inviolável do indivíduo. Por isso, nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou: [170](#)

- a) para prestar socorro em caso de desastre ou para cumprir determinação judicial;
- b) desastre, ou para prestar socorro, ou, de dia ou à noite, por determinação judicial;
- c) desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
- d) para prestar socorro, ou, em qualquer hora do dia ou da noite, mediante determinação judicial, necessária esta mesmo em caso de desastre.

6. (OAB/102.º) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5.º, XXXV). Tal dispositivo consagra o princípio:

- a) do juiz natural;
- b) do remédio de injunção;
- c) da tutela jurisdicional;
- d) da isonomia perante a lei.

7. (OAB/102.º) Assinale a alternativa correta:

- a) a pena de morte não pode ser aplicada no Brasil, em nenhuma hipótese;
- b) a pena de morte pode ser introduzida no Brasil por meio de emenda constitucional;
- c) a pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada;
- d) a pena de morte pode ser introduzida em processo de revisão constitucional.

- b) é privado do *status* de cidadão e dos direitos dele decorrentes;
- c) tem seus direitos e garantias individuais suspensos;
- d) não pode ser privado de nada, porque a Constituição prevê liberdade de credo religioso.

9. (OAB/105.º) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa norma:

- a) proíbe atos jurídicos imperfeitos;
- b) permite a retroatividade da lei;
- c) proíbe a retroprojeção da lei;
- d) faculta ao legislador a iniciativa de certas leis.

10. (OAB/109.º) Artistas que participaram de uma telenovela que, após exibição no Brasil, será reapresentada no exterior, encontram proteção à sua participação nos lucros, nas garantias constitucionais:

- a) do direito adquirido;
- b) de proteção à reprodução da imagem e voz;
- c) da inviolabilidade das comunicações;
- d) do direito à liberdade de expressão da atividade artística.

11. (MP/82.º) Assinale o enunciado que não está em consonância com um dos incisos do art. 5.º, da Constituição Federal:

- a) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária;
- b) não intentada a ação penal pública dentro do prazo legal, será admitida ação penal privada;
- c) é permitido reunir-se pacificamente, sem armas, em lugar aberto ao público, independentemente de prévio aviso à autoridade competente, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada;
- d) o estrangeiro não será extraditado em razão de prática de crime político ou de opinião;
- e) não haverá identificação criminal daquele que já possuir identificação civil, salvo nas hipóteses previstas em lei.

12. (OAB/119.º) A Constituição Federal assegura expressamente, em seu art. 5.º:

- I. o direito de herança;

- II. a impenhorabilidade do bem de família;
- III. ao preso, o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

Pode-se afirmar que estão corretos os itens

- a) I e II, apenas;
- b) I e III, apenas;
- c) II e III, apenas;
- d) I, II e III.

13. (CESPE/UnB Defensoria Pública DF/2006) Com referência ao uso de algemas em pessoas investigadas ou processadas criminalmente, julgue os itens que se seguem sob a perspectiva dos direitos e das garantias fundamentais.

- 1. É possível inferir, a partir dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma forma juridicamente válida de uso de algemas, embora, acerca dessa matéria, haja omissão nos Códigos Penal e de Processo Penal.
- 2. Em situações em que o preso não demonstre reação violenta nem recuse as providências policiais necessárias à sua condução, não está autorizada a utilização de algemas.
- 3. As algemas não podem ser utilizadas sob o argumento de se evitar agressão do preso contra si mesmo.
- 4. O argumento da prevenção da fuga do preso só pode ser invocado para justificar o uso de algemas quando houver fundada suspeita ou justificado receio de que isso possa vir a ocorrer.

14. (Defensoria Pública SP — 2006 — FCC) O reconhecimento de iguais direitos aos homossexuais e a igual valoração jurídica das relações afetivas e eróticas entre pessoas do mesmo sexo:

- a) dependem de modificação constitucional através de manifestação do Poder Constituinte Derivado, uma vez que o inciso IV do art. 3.º não previu a discriminação por orientação sexual;
- b) ferem o princípio democrático e a regra da maioria, já que o Direito, ao determinar ou escolher uma moral, deve privilegiar a moral da maioria;
- c) decorrem do sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais, que proíbe quaisquer formas de discriminação e garante a dignidade da pessoa humana;

- d) estão sujeitos à evolução social e cultural da sociedade em que vivemos, uma vez que para o “homem comum” as práticas homossexuais são antinaturais e contrariam as convicções religiosas compartilhadas;
- e) necessitam de legislação infraconstitucional para efetivação, pois as normas constitucionais incidentes são de eficácia limitada.

15. (MP/MG 2007) É CORRETO afirmar que a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela:

- a) lei estrangeira.
- b) lei pessoal do *de cuius*, desde que não estrangeira.
- c) lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do *de cuius*.
- d) lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros.
- e) lei brasileira se mais favorável ao *de cuius*.

16. (MP/MG 2007) Constitui crime inafiançável e imprescritível:

- a) a prática da tortura.
- b) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- c) o terrorismo.
- d) os crimes hediondos.
- e) a prática do racismo.

17. (TRF — 2005 — ESAF) Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, marque a única opção correta.

- a) A impossibilidade de concessão de fiança para indiciados em crimes de tortura implica que esse indiciado não poderá responder ao processo judicial em liberdade.
- b) A proteção da honra, prevista no texto constitucional brasileiro, que se materializa no direito a indenização por danos morais, aplica-se apenas à pessoa física, uma vez que a honra, como conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, é qualidade humana.
- c) A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, prevista no texto constitucional brasileiro, é absoluta, não admitindo exceções destinadas a compensar juridicamente os desníveis materiais existentes ou atendimento de questões socioculturais.

admitindo exceções destinadas a compensar juridicamente os desníveis materiais existentes ou atendimento de questões socioculturais.

- d) A competência da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões é uma restrição à liberdade de ação profissional.
- e) Nos termos definidos na Constituição Federal, a objeção de consciência, que pode ser entendida como impedimento para o cumprimento de qualquer obrigação que conflite com crenças religiosas e convicções filosóficas ou políticas, não poderá ser objeto de nenhuma espécie de sanção sob a forma de privação de direitos.

18. (DPU — CESPE/UnB — 2010) A respeito dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Conforme entendimento do STF com base no princípio da vedação do anonimato, os escritos apócrifos não podem justificar, por si sós, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da *persecutio criminis*, salvo quando forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem eles próprios o corpo de delito.

19. (Procurador do Estado do Amazonas/FCC/2010) Considerando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a Constituição Federal, é correto afirmar que:

- a) a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
- b) é constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
- c) a prisão civil de depositário infiel é ilícita apenas no caso de depósito judicial.
- d) é constitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
- e) é inconstitucional lei federal que estabeleça prazo para a impetração de mandado de segurança.

20. (Procurador do Estado do Amazonas/FCC/2010) De acordo com o texto vigente da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os tratados internacionais, é correto afirmar que:

- a) todos os tratados internacionais firmados pelo Brasil ingressam no ordenamento jurídico brasileiro como normas de hierarquia constitucional.

- c) os tratados internacionais firmados pelo Brasil sobre direitos humanos podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia de emendas constitucionais.
- d) o procedimento de aprovação, pelas Casas do Congresso Nacional, dos tratados internacionais sobre direitos humanos é irrelevante para caracterizar sua hierarquia normativa.
- e) os tratados internacionais firmados pelo Brasil não podem versar sobre normas materialmente constitucionais.

21. (Exame da OAB Unificado 2010.1 — CESPE/UnB — caderno Miguel Reale) Assinale a opção correta com relação ao sigilo bancário.

- a) As comissões parlamentares de inquérito poderão determinar a quebra de sigilo bancário sem a interferência do Poder Judiciário, desde que o façam de forma fundamentada.
- b) A quebra do sigilo bancário pode ser determinada diretamente pelo Tribunal de Contas da União.
- c) A quebra do sigilo bancário está submetida à chamada reserva de jurisdição, podendo somente os juízes determiná-la e, ainda assim, de forma fundamentada.
- d) Conforme a lei complementar que rege a matéria, constitui quebra ilegal de sigilo bancário a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos administrativos, mesmo quando do fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa.

22. (Titular de Serviços de Notas e de Registros — TJ-MA — IESES/2011) Quanto à presença de crucifixos em cartórios e repartições públicas estaduais, pode-se dizer que:

- a) Seu término, com a singela retirada dos crucifixos, não implicaria violação à ordem constitucional vigente.
- b) Não é passível de questionamento com base no art. 19 da Constituição, pois esta só impõe a laicidade ao legislador federal.
- c) É obrigatória, em virtude da interpretação dada pelo STF ao Preâmbulo da Constituição Federal.
- d) Não configurará risco de ofensa à laicidade prevista no art. 19 da C.F. nem à igualdade referida no art. 5.º, *caput*, do mesmo diploma, quando o crucifixo estiver acompanhado de diversas outras imagens vinculadas à fé religiosa da maioria da população local.

23. (Analista de Controle Externo — TCE-AP — FCC/2012) Estabelece a Constituição

Federal que a casa é asilo inviolável do indivíduo e nela pode entrar, sem o consentimento do morador:

- a) qualquer pessoa em estado de miserabilidade.
- b) oficial de justiça, munido de autorização do juiz, a qualquer hora.
- c) qualquer pessoa para prestar socorro.
- d) oficial de justiça, munido de autorização administrativa, apenas durante o dia.
- e) policial militar munido de ofício de delegado de polícia.

24. (Agente de Polícia/AL — CESPE/UnB/2012) Acerca da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir:

O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes.

25. (Agente de Polícia/AL — CESPE/UnB/2012) Em relação aos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente:

A jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente. Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição da autoridade policial.

26. (Analista Ministerial — MP/PI — Área Processual — CESPE/UnB/2012) A respeito de direitos e garantias fundamentais e nacionalidade, julgue o item seguinte:

A vedação constitucional ao anonimato impede a utilização de peças apócrifas como prova formal.

27. (Inspetor de Polícia Civil/CE — CESPE/UnB/2012) Julgue o item que se segue, acerca do direito constitucional, considerando a Constituição da República de 1988 (CF):

Considere que uma manifestação pública realizada por determinado grupo religioso tenha atraído uma multidão hostil e que, quando a polícia foi chamada a intervir, o líder do grupo tenha chamado os policiais de fascistas, criando uma situação de perigo de pronta e violenta retaliação por parte dos policiais. Nessa situação, o líder do movimento está amparado pela garantia constitucional que assegura a liberdade de expressão.

28. (Analista Judiciário — Execução de Mandados — TRT10 — CESPE/UnB/2013) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos fundamentais:

Considere que um indivíduo tenha sido denunciado por crime contra o patrimônio há mais de dez anos e que, em razão da quantidade de processos conclusos para sentença na vara criminal do município, ainda não tenha havido sentença em relação ao seu caso. Essa situação retrata hipótese de flagrante violação ao direito fundamental à duração razoável do processo, expressamente previsto na CF.

29. (Analista Judiciário — Execução de Mandados — TRT10 — CESPE/UnB/2013) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos fundamentais:

A inviolabilidade do domicílio abrange qualquer compartimento habitado onde alguém exerce profissão ou atividades pessoais, podendo, por exemplo, ser um trailer, um barco ou um aposento de habitação coletiva.

30. (Analista Judiciário — CNJ — CESPE/UnB/2013) Acerca de direito constitucional, julgue o item a seguir:

Considere que um argentino tenha sido preso em flagrante em território brasileiro e que, com base no direito constitucional brasileiro, tenha impetrado *habeas corpus* redigido em língua espanhola. Nessa situação, a despeito de o pedido de *habeas corpus* destinar-se à salvaguarda de direito fundamental, o *writ* não deverá ser conhecido, pois é imprescindível o uso da língua portuguesa na redação dessa ação, consoante jurisprudência do STF.

31. (Agente de Polícia/SC — ACAFE — 2014) O art. 5.º da Constituição Federal trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie do gênero direitos e garantias fundamentais (Título II). Assim, apesar de referir-se, de modo expresso, apenas a direitos e deveres, também consagrou as garantias fundamentais. (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado, São Paulo: Saraiva, 2009, 13. ed., p. 671). Com base na afirmação acima, analise as questões a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos.

direitos.

- II. O rol dos direitos expressos nos 78 incisos e parágrafos do art. 5.º da Constituição Federal é meramente exemplificativo.
 - III. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte.
 - IV. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
 - V. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas III e V estão corretas.
 - d) Apenas IV e V estão corretas.
 - e) Todas as questões estão corretas.

■ 14.12.2. Remédios constitucionais

1. (Magistratura/170.º) Diretor de sociedade de economia mista da qual o Município participa pratica ato lesivo ao patrimônio da empresa. A anulação do ato pode ser pleiteada:

- a) em ação popular proposta por qualquer pessoa residente no País;
- b) em ação popular proposta por qualquer cidadão;
- c) apenas pelos que foram prejudicados pelo ato;
- d) em mandado de segurança impetrado por qualquer pessoa residente no Município.

2. (OAB/101.º) Ao direito à probidade e à moralidade da administração pública a Constituição Federal consagra uma garantia:

- a) *habeas corpus*;
- b) *habeas data*;
- c) ação popular;

3. (Magistratura/170.º) Autoridade administrativa recusa-se ilegalmente a fornecer certidão de tempo de serviço requerida por funcionário público, que dela necessita para pedir a aposentadoria. É cabível, nesse caso:

- a) mandado de injunção;
- b) *habeas data*;
- c) mandado de segurança;
- d) ação civil pública.

4. (OAB/115.º) Um cidadão, acessando uma página da Receita Federal na Internet, de propriedade do Governo Federal, descobre que os dados da sua última declaração encontram-se à disposição de todos os internautas. Para que seus dados sejam retirados daquela página, pode esse cidadão ingressar em juízo com:

- a) mandado de segurança;
- b) *habeas data*;
- c) mandado de injunção;
- d) ação popular.

5. (OAB/102.º) Determinada associação, regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, vê violado, por ato abusivo de autoridade pública, um direito líquido e certo seu. Para defender tal direito, essa associação deve lançar mão de:

- a) ação civil pública;
- b) mandado de segurança coletivo;
- c) mandado de segurança individual;
- d) mandado de injunção.

6. (OAB/106.º) São garantias dos direitos coletivos:

- a) o mandado de segurança coletivo e a sindicalização;
- b) o direito de greve e a ação popular;
- c) o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo e a ação popular;
- d) o mandado de segurança coletivo e a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania.

7. (OAB/107.º) A Reforma Administrativa determinou que a fixação do subsídio dos

ministros do STF será realizada por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF. Não tendo esta lei sido promulgada, pode-se entender que a inércia das autoridades responsáveis:

- a) não poderá ser suprida pelo mandado de injunção, visto tratar-se de iniciativa conjunta com o presidente do STF;
- b) poderá ser suprida por mandado de injunção, medida hábil a instrumentar o exercício de direitos decorrentes da ausência de norma reguladora;
- c) poderá ser suprida por meio de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ser proposta por qualquer servidor público prejudicado pela ausência de lei;
- d) poderá ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade.

8. (OAB/113.º) Uma rádio comunitária ingressa em juízo com mandado de injunção, temendo ser lacrada pelo órgão competente, eis que, nos termos da regulamentação existente, a mesma não teria autorização para funcionar. O mandado de injunção deve:

- a) ser concedido, como sucedâneo de *habeas data*;
- b) ser concedido, para assegurar o exercício de direitos e liberdades constitucionais inviabilizados pela falta de ato de autorização;
- c) ser negado, visto inexistir norma que regule tal tipo de serviço de radiodifusão;
- d) ser negado, visto existir norma regulamentadora desse serviço de radiodifusão.

9. (OAB/109.º) Uma pessoa teve um financiamento bancário negado pelo Banco do Brasil sob o argumento de que seu nome estaria registrado no Serviço de Proteção ao Crédito, como empresa devedora. Como se tratava de erro, a empresa deverá:

- a) ajuizar ação de reparação de danos contra o Serviço de Proteção ao Crédito, visto ser esta uma pessoa jurídica de direito privado e *habeas data* só pode ser impetrado contra pessoa jurídica de direito público;
- b) impetrar apenas mandado de segurança, porque pessoa jurídica não tem legitimidade para ajuizar *habeas data*;
- c) apresentar requerimento de informações à entidade depositária do seu registro, pedir a retificação dos dados inexatos e, se não obtiver êxito, ajuizar pedido de *habeas data* perante o Judiciário;

- d) ajuizar *habeas data* contra o Banco do Brasil, visto ser esta entidade estatal (sociedade de economia mista).

10. (AGU — CESPE/UnB — 2010) Quanto a direitos e garantias individuais e coletivos, julgue o item a seguir:

- I) A CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Nesse sentido, não sendo atendido o pedido de certidão, por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio cabível será o *habeas data*.
- II) O *habeas corpus* constitui, segundo o STF, medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal.

11. (Auxiliar Administrativo — DEGASE — CEPERJ/2007) O habeas corpus surge no Direito Brasileiro na Constituição de:

- a) 1937.
- b) 1891.
- c) 1988.
- d) 1934.
- e) 1946.

12. (Defensor Público/MA — CESPE/UnB/2011) Acerca das ações constitucionais, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência majoritária do STF:

- a) Em caso de omissão legislativa, cabe ao STF, em sede de mandado de injunção, proferir sentença de perfil aditivo a fim de criar regulação provisória pelo próprio Poder Judiciário.
- b) Não é cabível a impetração de mandado de segurança por parlamentar cujo objetivo seja o controle incidental de constitucionalidade relacionado à válida elaboração das proposições normativas em curso na respectiva casa legislativa.
- c) O *habeas corpus*, destinado a garantir a liberdade de locomoção do indivíduo, foi uma inovação da CF.
- d) Não é cabível *habeas corpus* para impugnar os pressupostos de legalidade de punição disciplinar militar, ainda que não se questione o mérito desta.
- e) É cabível a impetração de mandado de injunção para conhecer as razões de foro íntimo que levem o juiz a declarar-se suspeito para julgar a causa.

13. (Advogado — Petrobras — CESGRANRIO/2011) A ação popular, prevista no art. 5.º, LXXIII, da Constituição da República, pode ser ajuizada por (pelo):

- a) apátrida para anular ato praticado pelo Presidente da República.
- b) estrangeiro, residente no país há, pelo menos, dez anos, contra ato praticado por autarquia federal.
- c) ex-deputado federal, no gozo dos direitos políticos, para anular ato praticado por sociedade de economia mista.
- d) associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa de seus associados.
- e) Ministério Público para tutelar direitos difusos.

14. (Analista de Controle — TCE-PR — FCC/2011) João necessita, com urgência, de uma certidão pública com informações sobre o montante de uma dívida tributária em face do fisco estadual para juntar em um processo judicial. Dirigiu-se à repartição pública competente para solicitá-la, mas foi informado, por funcionário local, de que a repartição estava em reforma e, por esse motivo, a certidão só poderia ser expedida em um prazo mínimo de dois meses. Em face da urgência de João, o remédio constitucional adequado para proteger seus direitos é

- a) o *habeas data*.
- b) a ação popular.
- c) o mandado de segurança.
- d) o mandado de injunção.
- e) a ação civil pública.

15. (Analista Processual TJ/RR — CESPE/UnB/2012) No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir:

Embora apenas o cidadão tenha legitimidade para o ajuizamento da ação popular, o Ministério Público pode, na hipótese de desistência da ação por parte do autor, promover o respectivo prosseguimento do feito.

16. (Analista Processual TJ/RR — CESPE/UnB/2012) No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, bastando, para se configurar essa representação, a existência de um único parlamentar na Câmara dos Deputados ou no

Senado Federal, filiado ao partido.

17. (Técnico Judiciário — TJ/RR — CESPE/UnB/2012) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e à cidadania, julgue o próximo item:

Considere que Antônio, preso político durante a ditadura, pretenda obter informações de seu interesse constantes de banco de dados de entidade governamental. Considere, ainda, que o pedido de Antônio seja indeferido na esfera administrativa. Nessa situação, Antônio deverá impetrar *habeas corpus* junto ao Poder Judiciário a fim de obter as informações desejadas.

■ GABARITO ■

■ 14.12.1. Direitos fundamentais
1. “d”.
2. “b”. De acordo com o art. 5.º, LI, e configurando uma das situações em que a Constituição desiguala o brasileiro nato do naturalizado: a) brasileiro nato: nunca será extraditado; b) brasileiro naturalizado: b.1) crime comum — somente se praticado antes da naturalização; b.2) comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei — não importa o momento do fato, podendo ser extraditado se praticou o crime antes ou depois da naturalização.
3. “b”. Art. 5.º, LV.
4. “c”. Art. 5.º, XIV.
5. “c”. Cf. art. 5.º, XI.
6. “c”.
7. “c”. De acordo com o art. 5.º, XLVII, “a”. Não poderá ser introduzida através de emenda constitucional, por ferir a cláusula pétrea do direito e garantia individual, prevista no art. 60, § 4.º, IV.
8. “b”. De acordo com o art. 5.º, VIII, combinado com o art. 15, IV.

9. “c”. De acordo com o art. 5.º, XXXVI.
10. “b”. De acordo com o art. 5.º, XXVIII, “a”.
11. “c”. Cf. os incisos: LXI, LIX, XVI, LII e LVIII, todos do art. 5.º da CF/88.
12. “b”. Os direitos I e III estão previstos nos respectivos incisos XXX e LXIV do art. 5.º da CF/88. O direito da impenhorabilidade do bem de família não está assegurado expressamente na CF, mas decorre do sistema, especialmente do art. 226, <i>caput</i> (<i>vide, v.g., JTJSP-LEX 141/246 e STJ, REsp 6.708/PR</i>). Como a questão pedia para assinalar os direitos expressamente previstos no art. 5.º, corretos somente os itens I e III. Cuidado com este tipo de “pegadinha” que, infelizmente, aparece nos concursos e “derruba” bons candidatos!
13. Todas as proposições estão corretas, exceto a de número 3. Isso porque o STF entendeu que “o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. O emprego dessa medida tem como balizamento jurídico necessário os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.08.2006, <i>DJ</i> de 02.02.2007).
14. “c”. Cf. <i>Inf. 414/STF</i> (ADI-3.300) — Homoafetividade — União entre pessoas do mesmo sexo — Qualificação como entidade familiar (Transcrições).
15. “c”. Art. 5.º, XXXI, da CF/88.
16. “e”. Art. 5.º, XLII, da CF/88.
17. “d”, cf. arts. 5.º, XIII, e 22, XVI. Observamos que, segundo a doutrina, a regra do art. 5.º, XIII, é norma de eficácia contida, ou, ainda, reduzível ou restringível. O exemplo de redução é a Lei federal n. 8.906/94, que exige, do bacharel em direito, a aprovação no Exame de Ordem (OAB) para advogar (exigência declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 603.583, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2011). A letra “a” está errada. Cf. art. 5.º, XLIII; art. 5.º, LVII (presunção de inocência — não culpabilidade), e art. 5.º, LXVI. Cf., ainda, Lei n. 11.464/2007, que deu nova redação à <i>Lei de Crimes Hediondos</i> (Lei n. 8.072/90) e arts. 310, parágrafo único, e 312 do Código de Processo Penal. Assim, a prisão que tenha caráter cautelar terá de ser sempre

fundamentada, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência (cf. como exemplo, no site do STJ, *HC 134.247* — j. 13.08.2009). Sobre tráfico de drogas, por outro lado, cf. *Inf. 499/STF* e art. 44 da nova Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), que impede a liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico. *Com o máximo respeito, achamos que o examinador entrou em detalhamentos da matéria direito e processo penal para Analista da Receita Federal.* Ainda, convém alertar julgamento do Min. Eros Grau, no HC 100.872, em 05.10.2009. Conforme noticiado, “o ministro Eros Grau, do STF, concedeu liminar em *Habeas Corpus* impetrado pela defesa de uma mulher presa em flagrante com dois papérolas de cocaína. A decisão permite que a acusada responda ao processo em liberdade. Em seu despacho, o ministro afirma que o dispositivo da nova Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06), que impede a liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III), da presunção de inocência (art. 5.º, LVII) e do devido processo legal (art. 5.º, LIV)... Embora tenha admitido que o STF vinha adotando o entendimento mencionado pelo STJ, o ministro Eros Grau citou, em sua decisão, precedente do ministro Celso de Mello (HC 97.976) no qual afirma a violação dos princípios constitucionais acima citados, acrescentando que ‘o tema está a merecer reflexão por esta Corte, sob o ponto de vista da proibição de excessos decorrentes da atividade normativa do Estado’ (*Notícias STF*, 05.10.2009). A letra “b” está errada. De fato, nos termos do art. 5.º, X, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Quando o texto afirma essa proteção às **pessoas, deve ser entendido não apenas as pessoas físicas.** Nesse sentido, a Súmula 227/STJ estabelece: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Estamos diante da possibilidade de ataque à honra objetiva da pessoa jurídica, qual seja, o seu nome, a sua reputação. A letra “c” está errada. Conforme já escrevemos, o art. 5.º, *caput*, consagra serem todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal (consagrada no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade material, na medida em que a lei deverá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. A letra “e” está errada por violar o art. 15, IV. Tratamos desse assunto no capítulo sobre direitos políticos (*item 17.4.2.1*).

18. “certo”.

19. “a”. Nesse sentido, cf. SV 5/STF.

20. “c”.

21. “a”.
22. “a”.
23. “c”.
24. “certo”. Cf. <i>Súmula Vinculante 11/STF</i> .
25. “errado”. Por se tratar de reserva de jurisdição, o acesso a dados bancários não poderá ser requisitado por autoridade policial, mas, apenas, judicial.
26. “errado”.
27. “errado”, em razão da característica da limitabilidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são absolutos.
28. “certo”, art. 5.º, LXXVIII.
29. “certo”.
30. “certo”. Cf. HC 72.391-QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 08.03.1995, Plenário, <i>DJ</i> de 17.03.1995).
31. “e”.
■ 14.12.2. Remédios constitucionais
1. “b”. Art. 5.º, LXXIII.
2. “c”. Art. 5.º, LXXIII.
3. “c”. Art. 5.º, LXIX, combinado com o art. 5.º, XXXIV, “b” (<i>vide</i> parte teórica quando diferenciamos com o <i>habeas data</i>).
4. “a”. Art. 5.º, LXIX. O cidadão tem o direito líquido e certo seu, não amparado por <i>habeas corpus</i> ou <i>habeas data</i> , de não ter os seus dados pessoais tomados públicos na Internet pela Receita Federal. Trata-se de sigilo fiscal (comunicação de dados, art. 5.º, XII) que deve ser respeitado pela autoridade fazendária, além, é claro, do direito à intimidade e à vida privada (art. 5.º, X).

Lembramos a LC n. 104/2001, que prevê situação em que é permitida a prestação de informações pela Fazenda Pública, mas apenas por solicitação de autoridade administrativa e no interesse da Administração Pública, havendo necessidade de ser comprovada a instauração de regular processo administrativo, com o objetivo de investigar o sujeito passivo. Conforme visto na parte teórica, consideramos essa novidade trazida pela LC n. 104/2001 totalmente inconstitucional; resta aguardar o posicionamento do STF (matéria pendente).
5. “c”. Art. 5.º, LXIX. Trata-se de “direito líquido e certo seu”, ou seja, da associação pessoa jurídica, não tendo nenhuma relação com o direito coletivo de seus associados, motivo pelo qual não se trata de mandado de segurança coletivo.
6. “c”.
7. “b”. Art. 5.º, LXXI. 171 Lembrar que a Reforma da Previdência (EC n. 41/2003) acabou com a modalidade denominada iniciativa conjunta (cf. arts. 37, XI, e 48, XV).
8. “d”. Art. 5.º, LXXI. A falta de norma regulamentadora de norma constitucional de eficácia limitada é fundamental para que se possa falar em MI.
9. “c”. Art. 5.º, LXXII, combinado com a Lei n. 9.507, de 12.11.1997.
10. I) “errado”, já que o remédio, conforme visto na parte teórica, é o mandado de segurança. II) “certo”.
11. “b”.
12. “a”.
13. “c”.
14. “c”. Conforme visto na parte teórica, não confundir com o <i>habeas data</i> , pois, no caso citado, está claro o direito líquido e certo à obtenção da certidão.
15. “certo”, nos termos do art. 9.º da Lei n. 4.717/65.
16. “certo”, de acordo com a parte teórica.
17. “errado”. A resposta correta seria <i>habeas data</i> .

DIREITOS SOCIAIS

15.1. ASPECTOS GERAIS



Nos termos do art. 6.º, na redação dada pelas ECs ns. 26/2000 e 64/2010, são **direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Trata-se de desdobramento da perspectiva de um **Estado Social de Direito**, tendo como documentos marcantes a Constituição mexicana de 1917, a de Weimar, na Alemanha, de 1919, e, no Brasil, a de 1934.

Sem dúvida, os direitos sociais previstos no art. 6.º caracterizam-se como o conteúdo da ordem social, que aparece bem delimitada em um título próprio da Constituição e que será estudada no *capítulo 19*.

Segundo José Afonso da Silva, os **direitos sociais** “disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto”, sendo que “os **direitos econômicos** constituirão pressupostos da existência dos direitos sociais, pois sem uma política econômica orientada para a intervenção e participação estatal na economia não se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático de conteúdo tutelar dos fracos e dos mais numerosos”.¹

Assim, os **direitos sociais**, direitos de **segunda dimensão**, apresentam-se como **prestações positivas** a serem implementadas pelo Estado (Social de Direito) e tendem a concretizar a perspectiva de uma **isonomia substancial e social** na busca de melhores e adequadas condições de vida, estando, ainda, consagrados como **fundamentos** da República Federativa do Brasil (art. 1.º, IV, da CF/88).

Enquanto **direitos fundamentais** (alocados no Título II da CF/88), os direitos sociais têm **aplicação imediata** (art. 5.º, § 1.º) e podem ser implementados, no caso de omissão legislativa, pelas técnicas de controle, quais sejam, o **mandado de injunção** ou a **ADO** (*ação direta de inconstitucionalidade por omissão*).

■ 15.2. BREVES COMENTÁRIOS AOS DIREITOS SOCIAIS

Podemos, então, fazer alguns breves comentários sobre cada um dos direitos sociais elencados no art. 6.º:

■ 15.2.1. Direito à educação

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho.

Importante destacar que, nos termos da **Súmula Vinculante 12/STF**, “a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”.

Chamamos, aqui, atenção para a discussão que surgiu na **ADO 1.698** (*ação direta de inconstitucionalidade por omissão*), ajuizada em 29.10.1997 pelos partidos políticos PT, PC do B e PDT, e que veio a ser decidida pelo STF depois de **12 anos de tramitação**.

Os partidos requeriam a declaração de inconstitucionalidade em razão da inércia governamental na área da educação, pedindo o reconhecimento de que o Governo estava sendo omisso na erradicação do analfabetismo e, assim, que se fixasse o prazo de 30 dias para a adoção de medidas efetivas.

O STF, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, apesar de reconhecer que muito ainda precisa ser feito em relação à educação no Brasil, julgou **improcedente** o pedido. Vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 6.º, 23, V, 208, I, e 214, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA INÉRCIA ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA ERRADICAR O ANALFABETISMO NO PAÍS E PARA IMPLEMENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO E GRATUITO A TODOS OS BRASILEIROS. 1. Dados do recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram redução do índice da população analfabeta, complementado pelo aumento da escolaridade de jovens e adultos. 2. **Ausência de omissão por parte do Chefe do Poder Executivo federal** em razão do elevado número de programas governamentais para a área de educação. 3. A edição da Lei n. 9.394/96 (*Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*) e da Lei n. 10.172/2001 (*Aprova o Plano Nacional de Educação*) demonstra atuação do Poder Público dando cumprimento à Constituição. 4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão improcedente” (ADI 1.698, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.02.2010, Plenário, DJE de 16.04.2010).

■ 15.2.2. Direito à saúde

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante **políticas sociais** e **econômicas** que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

São de **relevância pública** as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197).

Como se sabe, a doutrina aponta a **dupla vertente** dos direitos sociais, especialmente no tocante à saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: **a) natureza negativa:** o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; **b) natureza positiva:** fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social.

■ 15.2.3. Direito à alimentação

De acordo com a *justificação* da *PEC n. 21/2001-SF*, “o **direito à alimentação** foi reconhecido pela *Comissão de Direitos Humanos da ONU*, em 1993, em reunião realizada na cidade de Viena. Integrada por 52 países, e contando com o voto favorável do Brasil, registrando apenas um voto contra (EUA), a referida Comissão da ONU com essa decisão histórica enriqueceu a Carta dos Direitos de 1948, colocando em primeiro lugar, entre os direitos do cidadão, a alimentação” (cf. art. XXV da *Declaração Universal dos Direitos Humanos* de 1948).

Antes mesmo da **EC n. 64/2010**, que introduziu o **direito à alimentação** como **direito social**, a **Lei n. 11.346/2006**, regulamentada pelo Dec. n. 7.272/2010, já havia criado o *Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional* — *SISAN* com vistas a assegurar o **direito humano à alimentação**

adequada.

O art. 2.º da referida lei define a **alimentação adequada** como **direito fundamental do ser humano**, inerente à **dignidade da pessoa humana** e **indispensável** à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

Assim, muito bem-vinda a previsão constitucional da *alimentação* como direito social, apesar do atraso, diga-se de passagem.

■ 15.2.4. Direito ao trabalho

Trata-se, sem dúvida, de relevante instrumento para implementar e assegurar a todos uma **existência digna**, como estabelece o art. 170, *caput*. O Estado deve fomentar uma política econômica não recessiva, tanto que, dentre os princípios da ordem econômica, sobressai a **busca do pleno emprego** (art. 170, VIII). Aparece como **fundamento** da República (art. 1.º, IV), e a **ordem econômica**, conforme os ditames da justiça social, funda-se na **valorização do trabalho humano** e na **livre-iniciativa**.

■ 15.2.5. Direito à moradia

O direito à moradia foi previsto de modo expresso como direito social pela **EC n. 26/2000**.

Apesar dessa incorporação tardia ao texto, desde a promulgação da Constituição o direito de moradia já estava amparado, pois, na dicção do art. 23, IX, todos os entes federativos têm competência administrativa para **promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico**.

Também, partindo da ideia de dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III), direito à intimidade e à privacidade (art. 5.º, X) e de ser a casa asilo inviolável (art. 5.º, XI), não há dúvida de que o direito à moradia busca consagrar o direito

à habitação digna e adequada, tanto é assim que o art. 23, X, estabelece ser atribuição de todos os entes federativos combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

Parece-nos, também, que a Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a **impenhorabilidade do bem de família**, encontra fundamento no art. 6.º da CF/88.

Entre as ressalvas da referida lei, ou seja, não proteção mesmo em se tratando do único bem imóvel, está a figura do **fiador** em contrato de aluguel (art. 3.º, VII).

Levada a questão ao STF, por 7 x 3, em **08.02.2006**, entenderam os Ministros que “o único imóvel (bem de família) de uma pessoa que assume a condição de fiador em contrato de aluguel **pode ser penhorado**, em caso de inadimplência do locatário”, e, assim, não violando o direito de moradia enquanto direito fundamental (RE 407.688; AI 576.544-AgR-AgR).

Isso porque, fortalecendo o entendimento, nos termos do direito de liberdade, ninguém é obrigado a ser fiador; mas, assumindo esse encargo, terá de arcar com responsabilidades.

Ainda, a ressalva constante do art. 3.º, IV, da Lei n. 8.009/90 (não aplicação da regra da impenhorabilidade para a cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar) também é **constitucional**, segundo a interpretação do STF, não violando o direito à moradia, nem mesmo o direito de propriedade.

No caso, entendeu-se que “... não haveria que se falar em impenhorabilidade do imóvel, uma vez que o pagamento de contribuição condominial (obrigação *propter rem*) é essencial à conservação da propriedade, isto é, à garantia da subsistência individual e familiar — dignidade da pessoa humana. Asseverou-se que a relação condominial tem natureza tipicamente de uma **relação de comunhão de escopo**, na qual os interesses dos contratantes são paralelos e existe identidade de objetivos, em contraposição à de intercâmbio, em que cada parte tem por fim seus próprios interesses, caracterizando-se pelo vínculo

sinalagmático” (*Inf. 455/STF — RE 439.003*, Rel. Min. Eros Grau, j. 06.02.2007, *DJ* de 02.03.2007).

■ 15.2.6. Direito ao lazer

Na lição de José Afonso da Silva, “lazer e recreação são funções urbanísticas, daí por que são manifestações do direito urbanístico. Sua natureza social decorre do fato de que constituem prestações estatais que interferem com as condições de trabalho e com a qualidade de vida, donde sua relação com o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. ‘Lazer’ é entrega à ociosidade repousante. ‘Recreação’ é entrega ao divertimento, ao esporte, ao brinquedo. Ambos se destinam a refazer as forças depois da labuta diária e semanal. Ambos requerem lugares apropriados, tranquilos, repletos de folguedos e alegrias”.²

Por fim, cabe lembrar que o art. 217, § 3.º, estabelece ser dever do Poder Público incentivar o lazer como **forma de promoção social**.

■ 15.2.7. Direito à segurança

O direito à segurança também aparece no *caput* do art. 5.º. Porém, a previsão no art. 6.º tem sentido diverso daquela no art. 5.º. Enquanto lá está ligada à ideia de garantia individual, aqui, no art. 6.º, aproxima-se do conceito de **segurança pública**, que, como dever do Estado, aparece como direito e responsabilidade de todos, sendo exercida, nos termos do art. 144, *caput*, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

■ 15.2.8. Direito à previdência social

Conforme anotou José Afonso da Silva, **previdência social** “é um conjunto de direitos relativos à seguridade social. Como manifestação desta, a previdência tende a ultrapassar a mera concepção de instituição do Estado-providência (*Welfare State*), sem, no entanto, assumir características socializantes — até

porque estas dependem mais do regime econômico do que do social”.³

■ 15.2.9. Proteção à maternidade e à infância

Partindo do art. XXV da *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, de 1948, o texto de 1988 consagrou a **proteção à maternidade** como indiscutível **direito social**.

A proteção à **maternidade** aparece tanto com natureza de **direito previdenciário** (art. 201, II) como de **direito assistencial** (art. 203, I).

A teor do **art. 201, II**, a proteção à maternidade deverá ser atendida pela **previdência social**, sendo um dos objetivos da assistência social.

Cabe registrar que essa desoneração do empregador já havia sido assegurada anteriormente pela Lei n. 6.136/74, caracterizando importante conquista no sentido da não discriminação entre o homem e a mulher no momento da contratação.

O art. 7.º estabeleceu a licença à gestante (inciso XVIII) como um dos direitos dos trabalhadores, assim como a licença-paternidade (inciso XIX).

Por sua vez, o § 3.º do art. 39 também garantiu a licença-gestante à servidora pública e a licença-paternidade ao servidor.

A Constituição determinou, ainda, que a licença à gestante será de **120 dias**, sendo a licença-paternidade de **5 dias** (art. 10, § 1.º, do ADCT).

Os prazos para a licença à gestante de 120 dias e para a licença-paternidade de 5 dias também estão estabelecidos para os **servidores públicos** nos arts. 207 e 208 da Lei n. 8.112/90.

A legislação infraconstitucional, por seu turno, assegurou, de maneira acertada, a referida licença para o caso de **adoção**.

A Lei n. 11.770/2008, que instituiu o **Programa Empresa Cidadã**, regulamentada pelo Dec. n. 7.052/2009, permitiu a prorrogação da licença-maternidade por 60 dias, mediante incentivos fiscais às empresas, totalizando, assim, o período de 180 dias.

Essa novidade, contudo, mostra-se **tímida** e **discriminatória**, pois não atinge as empresas optantes pelo Simples e, ainda, depende da vontade do empresário de aderir ao programa.

Em igual sentido, referida lei autorizou a administração pública, direta, indireta e fundacional a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, consolidando-se tal previsão, no âmbito federal, nos termos do Decreto n. 6.690/2008.

Os avanços foram muito importantes, porém tímidos, insista-se. Nesse sentido, parece-nos extremamente importante a aprovação da PEC n. 30-A/2007, apensada à PEC 515/2010, que aumenta a licença à gestante para **180 dias**.

Cumpre, por fim, assinalar que a **proteção à infância** tem natureza **assistencial** (art. 203, I e II), havendo expressa previsão de proteção à criança, ao adolescente e ao jovem nos termos do art. 227, com a redação dada pela **EC n. 65/2010** (destacamos a Lei n. 12.852/2013 que instituiu o *Estatuto da Juventude* e dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude — SINAJUVE).

■ 15.2.10. Assistência aos desamparados

O direito social de assistência aos desamparados é materializado pelo art. 203, ao estatuir que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, **independentemente de contribuição à seguridade social**.

Além disso, conforme o disposto no art. 204, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes.

Sem dúvida, dentro da ideia de Estado prestacionista, ações afirmativas deverão ser implementadas.

■ 15.3. “PEC DA FELICIDADE” — PEC N. 513/2010-CD E PEC N. 19/2010-SF

Devemos deixar consignada a previsão de importantes PECs, tanto na Câmara dos Deputados (Deputada Manuela D’Ávila) como no Senado (Senador Cristovam Buarque), apresentadas conjuntamente na busca de aperfeiçoamento do art. 6.º, que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 6.º São direitos sociais, **essenciais à busca da felicidade**, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

As PECs em comentário visam proteger não a felicidade em seu aspecto *subjetivo*, o que significaria a busca de sentimentos muito particulares, mas, notadamente, o **aspecto objetivo** da felicidade que, segundo as propostas, pode ser normatizado no sentido de que a concretização dos direitos sociais leva a um estado geral (coletivo) de felicidade.

De acordo com as justificativas, “há **felicidade coletiva** quando são adequadamente observados os itens que tornam mais feliz a sociedade, ou seja, justamente os direitos sociais — uma sociedade mais feliz é uma sociedade mais bem desenvolvida, em que todos tenham acesso aos básicos serviços públicos de saúde, educação, previdência social, cultura, lazer, dentre outros”.

Em suas justificativas, os parlamentares lembram que a felicidade, enquanto direito, encontra-se positivada em diversos documentos, por exemplo:

■ **Declaração de Direitos da Virgínia (EUA, 1776):** outorgava-se aos homens o direito de buscar e conquistar a felicidade;

■ **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789):** “primeira noção coletiva de felicidade, determinando-se que as reivindicações dos indivíduos sempre se voltarão à felicidade geral”;

■ **Preâmbulo da Carta Francesa de 1958:** “consagra a adesão do povo francês aos Direitos Humanos consagrados na Declaração de 1789, dentre os quais se inclui, à toda a evidência, a felicidade geral ali preconizada”;

■ **Reino do Butão:** “estabelece, como indicador social, um *Índice Nacional de Felicidade Bruta (INFB)*, mensurado de acordo com indicadores que envolvem bem-estar, cultura, educação, ecologia, padrão de vida e qualidade de governo, determinando o artigo 9.º daquela Constituição o dever do Estado de promover as condições necessárias para o fomento do INFB”;

■ **Constituição do Japão:** o art. 13 “determina que todas as pessoas têm direito à busca pela felicidade, desde que isso não interfira no bem-estar público, devendo o Estado, por leis e atos administrativos, empenhar-se na garantia às condições por atingir a felicidade”;

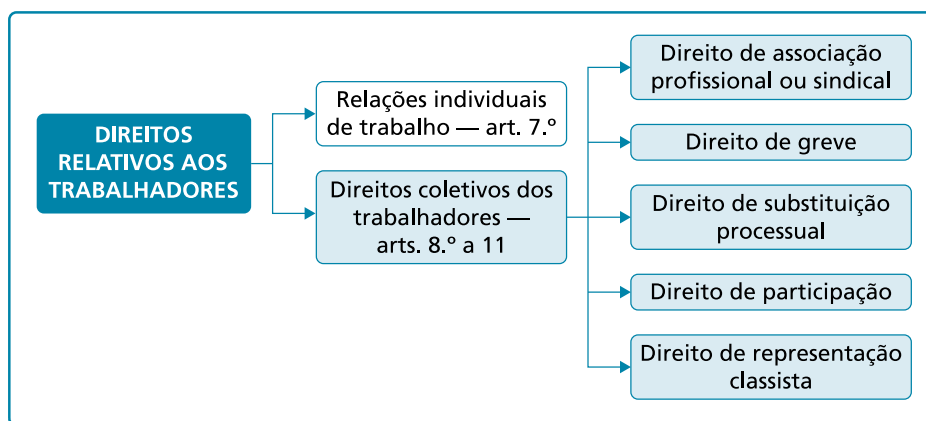
■ **Carta da Coreia do Sul:** o art. 10 estabelece que “todos têm direito a alcançar a felicidade, atrelando esse direito ao dever do Estado em confirmar e assegurar os direitos humanos dos indivíduos”.

Assim, muito importante a previsão e esperamos que o Congresso Nacional aprove a referida PEC.

Nessa linha, não podemos deixar de mencionar decisão proferida em 21.02.2006 pelo Juiz **Guilherme de Macedo Soares**, que, dentre outros argumentos, com base no **princípio da felicidade**, reconheceu a *união estável* entre pessoas do mesmo sexo.

Em suas palavras, “que fique claro que a felicidade aqui tratada não é aquela que não tem parâmetros, que invade a esfera jurídica do próximo ou até mesmo do Estado. Não, refiro-me àquela a que todos nós temos direito de ter e de buscar. **O ser humano não pode ser digno, ser livre, se não é feliz**” (argumentos da decisão).

■ 15.4. DIREITOS RELATIVOS AOS TRABALHADORES⁴



■ 15.4.1. Direitos sociais individuais dos trabalhadores

O art. 7.º estabelece um rol de direitos sociais dos **trabalhadores urbanos e rurais** (art. 7.º, *caput*), assim como dos **avulsos** (art. 7.º, XXXIV) e dos **domésticos**, cujos direitos foram profundamente ampliados pela **EC n. 72/2013** (art. 7.º, parágrafo único).

Cabe lembrar, ainda, que, nos termos do art. 39, § 3.º, aplica-se aos **servidores ocupantes de cargo público** o disposto no art. 7.º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Assim, pedimos vênia para transcrever os direitos sociais individuais dos trabalhadores:

- relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar,⁵ que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
- seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
- fundo de garantia do tempo de serviço;

CAUIDADO: o STF, por maioria (7 x 3), alterando a jurisprudência que vigorava por mais de 20 anos (RE 134.328, RE 116.761 e RE 120.189) estabeleceu que o **prazo prescricional** para a cobrança judicial de valores devidos, pelos empregados e pelos tomadores de serviço, ao Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço — FGTS, é de **5 anos**, observado o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para o ajuizamento da ação (**art. 7.º, XXIX, CF/88**), e não mais de 30 anos, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5.º, da Lei n. 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/90.

Assim, diante da **ruptura drástica** que se estabeleceu em relação à jurisprudência que preponderava, caracterizada a denominada “viragem jurisprudencial”, a Corte, em respeito ao **princípio da segurança jurídica**, determinou a **modulação dos efeitos da decisão** (técnica do *prospective overruling*), **dando efeitos a partir de então**, flexibilizando, assim, o princípio da nulidade.

Em *obiter dictum*, porque esse não era o objeto da demanda, a Corte sinalizou também pela aplicação da **prescrição quinquenal** quando a cobrança do FGTS for feita pelo próprio Fundo. Entendeu-se tratar-se o FGTS de norma acessória ao salário e resultante da relação de trabalho (dela decorrente), tendo inegável índole social e trabalhista (cf. **ARE 709.212/DF**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014, Plenário, *DJE* de 19.02.2015).

Nesse sentido, entendemos como **superadas** as **Súmulas 210/STJ** e **362/TST**.

■ salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Destacamos a **Lei n. 12.382/2011**, que dispôs sobre o valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo prazo, até 2015.

De acordo com o seu art. 3.º, os reajustes e aumentos fixados na forma do art. 2.º serão estabelecidos **pelo Poder Executivo**, por meio de **decreto**, nos termos da referida Lei, que divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo.

Contra essa sistemática normativa de divulgação oficial do valor do salário mínimo por decreto presidencial, foi ajuizada a ADI 4.568, sustentando-se a necessidade de lei em sentido formal, a ser editada anualmente.

Em 03.11.2011, por 8 x 2, o STF declarou constitucional o procedimento determinado na lei:

“EMENTA: (...). A exigência constitucional de lei formal para fixação do valor do salário mínimo está atendida pela Lei 12.382/2011. A utilização de decreto presidencial, definida pela Lei 12.382/2011 como instrumento de anúncio e divulgação do valor nominal do salário mínimo de 2012 a 2015, não desobedece o comando constitucional posto no inciso IV do art. 7.º da CB. A Lei 12.382/2011 definiu o valor do salário mínimo e sua política de afirmação de novos valores nominais para o período indicado (arts. 1.º e 2.º). **Cabe ao presidente da República, exclusivamente, aplicar os índices definidos legalmente para reajuste e aumento e divulgá-los por meio de decreto, pelo que não há inovação da ordem jurídica nem nova fixação de valor**” (ADI 4.568, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.11.2011, Plenário, DJE de 30.03.2012).

É de referir, ainda, a definição firme fixada pelo STF na **Súmula Vinculante 4**: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

■ piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

Muito embora a vedação constante do art. 7.º, IV, explicitada na citada Súmula Vinculante 4/STF, a Suprema Corte fez importante distinção entre o **salário mínimo** e o **piso salarial**.

Este último vem sendo fixado em valores distintos, seja em relação a categorias, seja em relação aos trabalhadores ou servidores dos Estados ou do DF.

Destacamos a **LC n. 103/2000** que, em razão da regra contida no art. 22, parágrafo único, da CF/88, **autorizou** os **Estados** e o **DF** a instituir, **mediante lei de iniciativa do Poder Executivo**, o **piso salarial** de que trata o art. 7.º, V,

da Constituição Federal, para os **empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho**.

Há, inclusive, decisão do STF afirmando que, se já houver lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, não terá o Estado competência para tratar do assunto, nem mesmo no sentido de se estabelecer um piso regional maior.⁶

De acordo com a referida *lei complementar federal*, não obstante o piso salarial possa ser estendido aos empregados domésticos, a autorização não poderá ser exercida: *a)* no segundo semestre do ano em que se verificar eleição para os cargos de Governador dos Estados e do Distrito Federal e de Deputados Estaduais e Distritais; *b)* em relação à remuneração de servidores públicos municipais.

Confira interessante julgado, aprofundando o instituto do *piso salarial*:

“... A lei questionada **não viola o princípio do pleno emprego**. Ao contrário, a instituição do piso salarial regional visa, exatamente, **reduzir as desigualdades sociais**, conferindo proteção aos trabalhadores e assegurando a eles melhores condições salariais. **Não viola o poder normativo da Justiça do Trabalho** (art. 114, § 2.º, da Lei Maior) o fato de a lei estadual não ter excluído dos seus efeitos a hipótese de piso salarial determinado em dissídio coletivo. A lei atuou nos exatos contornos da autorização conferida pela delegação legislativa. A lei impugnada realiza materialmente o **princípio constitucional da isonomia**, uma vez que o tratamento diferenciado aos trabalhadores agraciados com a instituição do **piso salarial regional visa reduzir as desigualdades sociais**. A LC federal 103/2000 teve por objetivo maior assegurar àquelas classes de trabalhadores menos mobilizadas e, portanto, com menor capacidade de organização sindical, um patamar mínimo de salário. A fim de manter-se o **incentivo à negociação coletiva** (art. 7.º, XXVI, CF/1988), **os pisos salariais regionais somente serão estabelecidos por lei naqueles casos em que não haja convenção ou acordo coletivo de trabalho**. As entidades sindicais continuarão podendo atuar nas negociações coletivas, desde que respeitado o patamar mínimo legalmente assegurado. A parte final do parágrafo único do art. 2.º da LC

459/2009 (estadual, acrescente-se), ao determinar a participação do ‘Governo do Estado de Santa Catarina’ nas negociações entre as entidades sindicais de trabalhadores e empregadores para atualização dos pisos salariais fixados na referida lei complementar, **ofende o princípio da autonomia sindical** (art. 8.º, I, CF/1988) e **extrapola os contornos da competência legislativa delegada pela União**. As negociações coletivas devem ocorrer com a participação dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, sem intromissão do governo (**princípio da negociação livre**). Ao criar mecanismo de participação estatal compulsória nas negociações coletivas, o Estado de Santa Catarina legisla sobre ‘direito coletivo do trabalho’, não se restringindo a instituir o piso salarial previsto no inciso V do art. 7.º da CF” (**ADI 4.364**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2011, Plenário, *DJE* de 16.05.2011).[7](#)

- irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
- garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
- décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
- remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
- proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
- participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
- salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei (redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998);
- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (*vide* Decreto-lei n. 5.452, de 1943);

- jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
- repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
- remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (*vide* Decreto-lei n. 5.452, art. 59, § 1.º);
- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias (cf. Lei n. 11.770, de 09.09.2008, que admite a prorrogação da licença por mais 60 dias — e acompanhem a tramitação da *PEC n. 30-A/2007*, que aumenta a licença à gestante para 180 dias);
- licença-paternidade, nos termos fixados em lei, atualmente de 5 dias, de acordo com o art. 10, § 1.º, ADCT;
- proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

Vale lembrar a publicação da **Lei n. 12.506/2011**, regulamentando o **aviso prévio proporcional** (art. 7.º, XXI, da CF/88), que será concedido na proporção de **30 dias** aos empregados que contem até **1 ano** de serviço na **mesma** empresa, sendo acrescidos **3 dias** por **ano** de serviço prestado na **mesma** empresa, até o **máximo de 60 dias**, perfazendo um total de até **90 dias** (quando, para essa hipótese, terá o empregado de ter trabalhado, na mesma empresa, por 21 anos — todo desdobramento dessa nova regra deverá dar-se nos livros de *direito do trabalho*).

- redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
- aposentadoria;

- assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas (redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006);
- reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
- proteção em face da automação, na forma da lei;
- seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
- ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (redação dada pela Emenda Constitucional n. 28, de 2000);
- proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
- proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
- proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998);
- igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;
- são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social (**EC n. 72/2013** e **LC n. 150/2015**).

■ 15.4.2. Direitos sociais coletivos dos trabalhadores (arts. 8.º a 11)

Os **direitos sociais coletivos** são aqueles exercidos pelos trabalhadores, coletivamente ou no interesse de uma coletividade, e podem ser classificados em:

- **direito de associação profissional ou sindical;**
- **direito de greve;**
- **direito de substituição processual;**
- **direito de participação;**
- **direito de representação classista.**

■ 15.4.2.1. *Direito de associação profissional ou sindical*

Nos termos do art. 8.º, *caput*, é livre a associação profissional ou sindical, observando-se as seguintes regras:

- a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Nesse ponto, citamos decisão da 1.^a Turma do STF que dispensou, para impetração de MS Coletivo, o registro dos estatutos do sindicato no Ministério do Trabalho, o que, em certo sentido, essa exigência, em nosso sentir, parecia ser uma regra importante para se demonstrar o preenchimento do **princípio da unicidade sindical**. De qualquer forma, vale a pena acompanhar essa jurisprudência que, em certo sentido, parece inovar (**tema pendente de análise aprofundada** — o acórdão abaixo citado não aprofunda o tema). Vejamos:

“EMENTA: Legitimidade — Mandado de segurança coletivo — Sindicato — Registro no Ministério do Trabalho. A legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo **indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no**

Ministério do Trabalho” (RE 370.834, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.2011, 1.^a Turma, DJE de 26.09.2011).

Não podemos deixar de registrar o entendimento, em sentido contrário, fixado pelo STF na **Súmula 677**: “até que lei venha a dispor a respeito, **incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade**” (Plenário, 24.09.2003, *DJ* de 09.10.2003). Resta aguardar como essa questão vai evoluir no STF.

- é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
- a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
- ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
- é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
- o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
- é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Finalmente, o art. 8.º, parágrafo único, prescreve que as disposições deste artigo aplicam-se à organização de **sindicatos rurais** e de **colônias de pescadores**, atendidas as condições que a lei estabelecer.

■ 15.4.2.2. *Direito de greve*

É assegurado o **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender (art. 9.º).

A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, sendo que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei (cf. **Lei n. 7.783/89**).

Como estudado no *item 14.11.5.4*, uma vez que ainda não foi disciplinado o direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII), o STF, no MI 712, determinou a aplicação da lei da iniciativa privada (a citada Lei n. 7.783/89) até que a matéria seja regulamentada pelo Congresso Nacional.

CUIDADO: entendeu o STF (cf. *item 13.7.9*) que alguns serviços públicos, em razão de sua **essencialidade** para a sociedade, deverão ser prestados em sua **totalidade**, como é, no caso, o serviço de segurança pública, determinando, por analogia, a aplicação da **vedação** para os militares e, assim, proibindo o seu exercício pelas polícias civis (cf. **Rcl 6.568**, Rel. Min. Eros Grau, j. 20.05.2009, Plenário, *DJE* de 25.09.2009).

Como alertamos no *item 11.8.4.4*, o STF editou a **SV 23/2009** com o seguinte teor: “a **Justiça do Trabalho** é competente para processar e julgar **ação possessória** ajuizada em **decorrência do exercício do direito de greve** pelos trabalhadores da iniciativa privada”.

■ 15.4.2.3. *Direito de substituição processual*

Conforme indicamos, nos termos do art. 8.º, III, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Nesse particular, importante destacar decisão do STF: “O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8.º, III, da Constituição e decidiu que os sindicatos têm **legitimidade processual para atuar na defesa de**

todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. A falta de publicação do precedente mencionado não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma controvérsia, em especial quando o entendimento adotado é confirmado por decisões posteriores. A nova composição do Tribunal não ensejou a mudança da orientação seguida. Agravo improvido” (RE 197.029-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.12.2006).

■ 15.4.2.4. *Direito de participação*

É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação (art. 10).

■ 15.4.2.5. *Direito de representação classista*

Nas empresas de mais de **200 empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores (art. 11).

■ 15.5. “METODOLOGIA FUZZY” E “CAMALEÕES NORMATIVOS” NA PROBLEMÁTICA DOS DIREITOS SOCIAIS, CULTURAIS E ECONÔMICOS (CANOTILHO)[8](#)

Como se sabe, os **direitos sociais, culturais e econômicos** são denominados direitos de **segunda dimensão** e, para sua implementação, exigem uma **prestação estatal**, o que, certamente, demandará **gasto público**.

Surge, então, o problemático dilema entre a efetivação de determinados direitos sociais e a alocação dos recursos financeiros que são **finitos**, ou seja, demandam escolhas a serem implementadas por meio das políticas públicas.

Conforme anotou o Min. Celso de Mello, “essa relação dilemática (...)”

conduz os Juízes deste Supremo Tribunal a proferir decisão que se projeta no contexto das denominadas **‘escolhas trágicas’** (GUIDO CALABRESI e PHILIP BOBBITT, ‘Tragic Choices’, 1978, W. W. Norton & Company), que nada mais exprimem senão o estado de **tensão dialética** entre a **necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das pessoas**, de um lado, e as **dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros**, sempre tão dramaticamente escassos, de outro” (voto — SL 47-AgR/PE, j. 17.03.2010).

A dificuldade intensifica-se quando se resolve enfrentar a problemática dos **direitos sociais** que exigem, como visto, a **prestação estatal**, pois, como diz Canotilho, os juristas não têm a sua exata dimensão, desprezando a necessidade de **análise econômica do direito**.

Em suas palavras, “como todos sabem, *fuzzy* significa em inglês ‘coisas vagas’, ‘indistintas’, indeterminadas. Por vezes, o estilo ‘fuzzysta’ aponta para o estilo do indivíduo. Ligeiramente embriagado. Ao nosso ver, paira sobre a dogmática e sobre a teoria jurídica dos direitos econômicos, sociais e culturais a carga metodológica da ‘vagueza’, ‘indeterminação’ e ‘impressionismo’ que a *teoria da ciência* vem apelidando, em termos caricaturais, sob a designação de ‘fuzzismo’ ou ‘metodologia fuzzy’. Em abono da verdade, este peso retórico é hoje comum a quase todas as ciências sociais. Em toda a sua radicalidade, a **censura do ‘fuzzismo’, lançada aos juristas**, significa basicamente que **eles não sabem o que estão a falar, quando abordam os complexos problemas dos direitos econômicos, sociais e culturais**”.⁹

Ainda, em aprofundada crítica, Canotilho denuncia a indeterminação normativa dos direitos sociais que vai repercutir na instável definição das políticas públicas. E explica, “... mesmo nos estritos parâmetros jurídico-dogmáticos, os direitos sociais aparecem envoltos em quadros pictóricos onde o recorte jurídico cede o lugar a nebulosas normativas. É aqui que surge o **‘camaleão normativo’**. A expressão não é nossa. Foi utilizada pelo conhecido constitucionalista alemão J. Isensee, há mais de quinze anos. Com ela, pretendia o Autor significar a **instabilidade** e **imprecisão normativa** de um **sistema**

jurídico aberto — como o dos direitos sociais — quer a conteúdos normativos imanentes ao sistema (*system-immanente*), quer a conteúdos normativos transcendentais ao mesmo sistema (*system-transcendente*). Esta indeterminação normativa explicaria, em grande medida, a confusão entre *conteúdo* de um direito, juridicamente definido e determinado, e *sugestão de conteúdo*, sujeita a modelações político-jurídicas cambiantes”.¹⁰

Essa problemática dos direitos sociais vem sendo analisada pelo STF, que ainda precisa delimitar, com mais precisão, os seus parâmetros¹¹ (**matéria pendente**). Em vários precedentes, o Tribunal já enfrentou o dilema, destacando-se dois importantes critérios de solução:

- **proibição da evolução reacionária;**
- **integridade e intangibilidade do núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”.**

■ 15.5.1. Princípio do não retrocesso social ou da proibição da evolução reacionária. Interpretação a ser dada à EC n. 86/2015 (fruto da “PEC do Orçamento Impositivo”)

Já vimos que, dentro de uma realidade de **Estado Social de Direito**, estabelece-se um comportamento positivo para a implementação dos direitos sociais, irradiando essa orientação para a condução das políticas públicas, para a atuação do legislador e para o julgador no caso de solução de conflitos.

Assim, o administrador, dentro da ideia da **reserva do possível**, deve implementar as políticas públicas.

O legislador, ao regulamentar os direitos, deve respeitar o seu **núcleo essencial**, dando as condições para a implementação dos direitos constitucionalmente assegurados.

Ainda, nesse mesmo contexto, deve ser observado o **princípio da vedação ao retrocesso**, isso quer dizer, uma vez concretizado o direito, ele não poderia ser diminuído ou esvaziado, consagrando aquilo que a doutrina francesa chamou de *effet cliquet*.

Entendemos que nem a lei poderá retroceder, como, em igual medida, o poder de reforma, uma vez que a emenda à Constituição deve resguardar os direitos sociais já consagrados.

Segundo anotou Canotilho, “o princípio da democracia econômica e social aponta para a **proibição de retrocesso social**. A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de ‘contrarrevolução social’ ou da ‘evolução reacionária’. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo”.¹²

Nesse contexto, devemos destacar a aprovação da denominada “PEC do Orçamento Impositivo”, transformada na **EC n. 86/2015**.

Estabelece-se uma necessidade de se observar um gasto mínimo federal em **saúde** de 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro (art. 198, § 2.º, I), valor esse a ser cumprido progressivamente e de modo escalonado dentro de 5 anos de sua promulgação, na forma do art. 2.º da EC n. 86/2015.

Élida Graziane Pinto e Ingo Sarlet, contudo, apontam, em interessante estudo, que a proposta significa um claro retrocesso, já que os valores são menores do que os estabelecidos pela EC n. 29/2000, quando era aplicado o valor de 14% da receita corrente líquida federal, caracterizando, assim, uma inaceitável perda de 0,8%.

Os autores propõem, então, que o regime previsto na EC n. 86/2015 seja interpretado como um **piso**, e não o teto de gasto em saúde. Além de sustentarem que as ações de saúde devem assegurar a garantia de um **mínimo existencial**, dentro de um contexto de **proibição de proteção insuficiente**, sustentam o **dever de progressividade na matéria**. Assim, “faz sentido também seja considerado **retrocesso** vedado constitucionalmente, além da extinção do arranjo protetivo do direito, a **estagnação imotivada**, bem como a interpretação restritiva que retire a possibilidade fática e jurídica de o direito fundamental à saúde ser realizado em caráter progressivo”.¹³

■ 15.5.2. Mínimo existencial: concretização dos direitos sociais e a implementação de políticas públicas

Importantes decisões do Judiciário brasileiro vêm sendo proferidas no sentido do controle e intervenção nas **políticas públicas**, especialmente em razão de **inércia estatal injustificável** ou da **abusividade governamental**. Nesse sentido, destacamos o voto do Min. Celso de Mello na **ADPF 45 MC/DF**:

“EMENTA: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. **Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais**. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da ‘reserva do possível’. **Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do ‘mínimo existencial’**. Viabilidade instrumental da arguição de descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração)”.

No tocante ao **fornecimento de medicamentos** não previstos na lista do SUS, ou custeamento pelo Estado de **tratamento de saúde** buscando aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, o STF vem proferindo decisões firmes e no sentido de se garantir o **direito à saúde**:

“O direito público subjetivo à saúde representa **prerrogativa jurídica indisponível** assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular — e implementar — políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O **direito à saúde** — além de qualificar-se como **direito fundamental** que assiste a todas as pessoas — representa **consequência constitucional indissociável do direito à**

vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. **A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.** O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política — que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado (...).¹⁴

Cabe alertar para o posicionamento do STF no sentido da **responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde**, merecendo atenção os seguintes preceitos normativos:

■ **art. 23, II, da CF/88:** estabelece ser **competência comum** da **União**, dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Municípios** cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

■ **art. 195, caput, da CF/88:** o financiamento do SUS, além de outras fontes, se implementa com recursos da seguridade social provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios (nesse sentido, cf. **SS 3.355**, j. 17.03.2010, reafirmada no **RE 855.178**, j. 13.03.2015).

■ **art. 7.º, XI, da Lei n. 8.080/90:** as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda, dentre outros princípios, à **conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos** da **União**, dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Municípios** na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Destacamos a **PSV 4/2008** (*proposta de súmula vinculante*), encaminhada pelo **Defensor Público-Geral Federal**¹⁵ que visa à edição de súmulas vinculantes que tornem expressas:

■ “a responsabilidade solidária dos Entes Federativos no que concerne ao fornecimento de medicamento e tratamento médico ao carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, a alegação de ilegitimidade passiva corriqueira por parte das Pessoas Jurídicas de Direito Público”;

■ “a possibilidade de bloqueio de valores públicos para o fornecimento de medicamento e tratamento médico ao carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, a alegação de que tal bloqueio fere o artigo 100, *caput* e § 2.º da Constituição de 1988”.

Referida *proposta de súmula vinculante* está **sobrestada**, aguardando o julgamento do **RE 566.471/RN**, que teve a repercussão geral reconhecida e no qual se discute a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos de alto custo (**matéria pendente de julgamento**).

Vejamos importante decisão do Min. Celso de Mello proferida em 23.03.2010 no **RE 482.611/SC**:

“EMENTA: Crianças e adolescentes vítimas de abuso e/ou exploração sexual. **Dever de proteção integral à infância e à juventude**. Obrigação constitucional que se impõe ao poder público. Programa *Sentinela — Projeto Acorde*. Inexecução, pelo Município de Florianópolis/SC, de referido programa de ação social cujo adimplemento traduz exigência de ordem constitucional. Configuração, no caso, de típica hipótese de **omissão inconstitucional imputável ao Município**. Desrespeito à Constituição provocado por inércia estatal (*RTJ* 183/818-819). Comportamento que transgredir a autoridade da lei fundamental (*RTJ* 185/794-796). **Impossibilidade de invocação, pelo poder público, da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial** (*RTJ* 200/191-197). Caráter **cogente e vinculante** das **normas**

constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas. Plena legitimidade jurídica do controle das omissões estatais pelo Poder Judiciário. A colmatção de omissões inconstitucionais como necessidade institucional fundada em **comportamento afirmativo** dos juízes e tribunais e de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal em tema de implementação de políticas públicas delineadas na Constituição da República (*RTJ* 174/687 — *RTJ* 175/1212-1213 — *RTJ* 199/1219-1220). Recurso extraordinário do Ministério Público Estadual conhecido e provido”.¹⁶

Em igual sentido, indispensável a leitura de voto do Min. Celso de Mello que determina a obrigatoriedade do Município de São Paulo (art. 211, § 2.º) de matricular crianças de até 5 anos de idade (art. 208, IV, da CF/88) em unidades de ensino infantil próximas de suas residências ou do endereço de trabalho dos responsáveis legais, sob pena de multa diária (*astreintes*):

“A **cláusula da reserva do possível — que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição** — encontra insuperável limitação na garantia constitucional do **mínimo existencial**, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanção direta do postulado da essencial **dignidade da pessoa humana**. (...) A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1.º, III, e art. 3.º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena **fruição de direitos sociais básicos**, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)” (**ARE 639.337-AgR**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011, 2.ª Turma, *DJE* de 15.09.2011).

■ 15.6. QUESTÕES

1. (Tec. Leg. Ass./Adm./CD/2007/FCC) Aos trabalhadores urbanos e rurais a Constituição Federal de 1988 assegura:

- a) a proibição de trabalho noturno a menores de vinte e um anos de idade.
- b) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.
- c) jornada de oito horas, em regra, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.
- d) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- e) ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de três anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

2. (ANAL/ADM/TST/2008) Acerca dos direitos fundamentais, julgue o item que se segue:

No que concerne ao direito de greve, a CF determina que lei ordinária definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

3. (Analista Judiciário — TRE-RJ — Área Administrativa — CESPE/UnB/2012) As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade mediata, já que, para que se efetivem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador.

4. (TJ/SP/2006) São direitos sociais, de acordo com a Constituição Federal:

- a) a educação, a saúde, a proteção à maternidade e à infância.
- b) o trabalho, a previdência social, a anistia e o salário família.
- c) a moradia, o lazer, a segurança e o *habeas corpus*.
- d) o salário mínimo, as férias e a assistência aos desamparados.

5. (6.º Concurso Público de Outorga de Delegações de Notas de Registro/TJ/SP/2009) Dentre os direitos sociais, nossa Carta Magna elenca o

direito dos trabalhadores urbanos ou rurais à

- a) remuneração do serviço extraordinário pelo menos 50% maior que a do normal.
- b) irredutibilidade do salário após um ano de trabalho ininterrupto e efetivo no cargo.
- c) remuneração isonômica entre o trabalhador diurno e o noturno.
- d) jornada de trabalho normal não superior a 10 horas diárias e 48 semanais.

6. (Atividades Notariais Registro/TJ/MS/Vunesp/2009) Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos trabalhadores, exceto:

- a) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
- b) participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração, nos termos da lei.
- c) salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.
- d) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
- e) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

7. (AFRFB/2005/ESAF) Sobre os direitos sociais, na Constituição de 1988, marque a única opção correta.

- a) Para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será sempre de seis horas.
- b) A Constituição Federal fixa que a remuneração do serviço extraordinário será superior em cinquenta por cento à do normal.
- c) O salário-família, pago em razão do dependente, é direito apenas do trabalhador considerado de baixa renda, nos termos da lei.
- d) Nos termos da Constituição Federal, é assegurada ao empregado a participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração, e à participação na gestão da empresa.
- e) A Constituição Federal assegura a eleição, nas empresas, de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

8. (TRF/2005/ESAF) Sobre direitos sociais, marque a única opção correta.

- a) A duração do trabalho normal tem previsão constitucional, não havendo a possibilidade de ser estabelecida redução da jornada de trabalho.
- b) Nos termos da Constituição Federal, a existência de seguro contra acidentes de trabalho, pago pelo empregador, impede que ele venha a ser condenado a indenizar o seu empregado, em caso de acidente durante a jornada normal de trabalho.
- c) A irredutibilidade do salário não é um direito absoluto do empregado, podendo ocorrer redução salarial, desde que ela seja aprovada em convenção ou acordo coletivo.
- d) A Constituição Federal assegura, como regra geral, a participação do empregado na gestão da empresa, salvo disposição legal em contrário.
- e) Não integra os direitos sociais, previstos na Constituição Federal, a assistência aos desamparados.

9. (Técnico Judiciário — área administrativa — TRT/9.ª Região — FCC 2010) Sobre os direitos sociais, é correto afirmar:

- a) Compete ao sindicato definir os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
- b) A Constituição Federal estabelece distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre os profissionais respectivos.
- c) Há proibição de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de treze anos.
- d) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Estado.
- e) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

10. (Defensoria Pública/SP — 2010) Em uma cidade, diversas mães têm comparecido no atendimento inicial da Defensoria Pública para se queixarem de que não têm conseguido vaga em creche municipal para seus filhos. O Defensor Público deve:

- a) orientar as mães a procurarem o serviço de assistência social do Município e elaborar os respectivos ofícios de encaminhamento.
- b) informar que é possível a propositura de ação civil pública, pois se trata de direito social

de natureza difusa, e encaminhar as mães para o Ministério Público.

- c) informar que se trata de direito constitucional de natureza social, mas que infelizmente há normas na Constituição chamadas de programáticas, bem como entendimento jurídico chamado de “reserva do possível”, que não recomendam o ajuizamento de ação nesse caso.
- d) orientar as mães a se organizarem e a denunciarem o fato na Ouvidoria Municipal, bem como marcar audiência com o Prefeito e procurar ajuda junto aos Vereadores a fim de que possam interferir na formulação do orçamento municipal.
- e) ajuizar ação judicial com base no direito à educação que compreende o atendimento em creche e pré-escola, pois a “reserva do possível” não pode ser oponível à realização do “mínimo existencial”.

11. (50.º MP/MG — 2010) Constituem direitos sociais previstos na Constituição da República, EXCETO:

- a) alimentação.
- b) atividade sexual.
- c) proteção à maternidade.
- d) trabalho.

12. (Defensoria Pública da União — CESPE/UnB-2010) Acerca da aplicabilidade e da interpretação das normas constitucionais, julgue o item seguinte:

Os direitos sociais previstos na Constituição, por estarem submetidos ao princípio da reserva do possível, não podem ser caracterizados como verdadeiros direitos subjetivos, mas, sim, como normas programáticas. Dessa forma, esses direitos devem ser tutelados pelo poder público, quando este, em sua análise discricionária, julgar favoráveis as condições econômicas e administrativas.

13. (Técnico Judiciário — TRE/ES — Área Administrativa — CESPE/UnB/2011) Acerca dos direitos e garantias constitucionais, julgue o item a seguir:

Os direitos sociais previstos na Constituição Federal advêm de normas de ordem pública, que não se revestem de imperatividade, podendo ser alteradas pela vontade das partes integrantes da relação trabalhista.

14. (Analista Judiciário — TRT/24 — Medicina — FCC/2011) O direito à eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o

entendimento direto com os empregadores é assegurado no caso de empresa com:

- a) até cem empregados.
- b) menos de cem empregados.
- c) até cento e vinte empregados.
- d) até cinquenta empregados.
- e) mais de duzentos empregados.

15. (Escrivão de Polícia — PC/ES — CESPE/UnB/2011) Julgue o item a seguir, acerca dos direitos sociais:

Na condição de direitos fundamentais, os direitos sociais são autoaplicáveis e suscetíveis de defesa mediante ajuizamento de mandado de injunção sempre que a omissão do poder público inviabilize seu exercício.

16. (Procurador do Estado/MT — FCC/2011) Como garantia da liberdade de associação profissional ou sindical, a Constituição da República prevê que:

- a) a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.
- b) os trabalhadores ou empregadores interessados definirão a base territorial para a criação de organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, não podendo a base, contudo, ser inferior à área de um Estado.
- c) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, salvo disposição contrária prevista nos atos constitutivos respectivos.
- d) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir de sua eleição para cargo de direção ou representação sindical, ainda que suplente, até dois anos após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- e) o aposentado filiado tem direito a votar nas organizações sindicais, embora não o tenha a ser votado.

17. (Oficial de Justiça — TJ/PE — FCC/2012) Aposentado resolveu candidatar-se ao cargo de Diretor do Sindicato do qual é filiado, o que gerou controvérsias entre os sindicalistas. Com base na Constituição Federal, é correto afirmar que:

- a) pode candidatar-se, desde que a sua aposentadoria tenha ocorrido a menos de dois

anos da candidatura.

- b) não pode candidatar-se por estar aposentado.
- c) pode candidatar-se, desde que a sua aposentadoria tenha ocorrido a menos de um ano da candidatura.
- d) pode candidatar-se, desde que haja previsão expressa na Convenção Coletiva de Trabalho de sua categoria profissional.
- e) o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, sendo, assim, permitida a sua candidatura.

18. (Câmara dos Deputados — Analista Legislativo — CESPE/UnB/2012) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte:

As negociações coletivas de trabalho devem contar obrigatoriamente com a participação dos sindicatos.

19. (Advogado/AGU — CESPE/UnB/2012) Julgue o item a seguir, acerca de remuneração e salário:

O salário mínimo é fixado por lei federal, em caráter nacional, de modo a garantir as necessidades vitais do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devendo os valores ser reajustados periodicamente para preservar o seu poder aquisitivo, vedada sua vinculação como indexador financeiro ou outro qualquer fim, podendo o valor ser declarado por decreto do presidente da República, se assim autorizado pela lei que fixar o modo de reajuste ou aumento.

20. (Juiz do Trabalho/TRT15/2013) Uma das características do constitucionalismo social é a integração de normas trabalhistas ao texto constitucional. No que se refere ao Brasil, a atual Constituição não expressa que:

- a) é proibida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- b) a relação de emprego é protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
- c) o seguro-desemprego é devido em caso de desemprego involuntário;
- d) o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não é devido em caso de pedido de demissão;

e) a garantia de salário, nunca inferior ao salário mínimo, é devida para os empregados que percebem remuneração variável.

21. (Técnico Judiciário — CNJ — Área Administrativa — CESPE/UnB/2013) (...) Julgue o item a seguir.

Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação dos sindicatos.

22. (Analista Judiciário — TRT10 — Área Judiciária — CESPE/UnB/2013) Julgue o próximo item, acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988:

O empregado filiado que vier a se aposentar perderá o direito de votar e de ser votado na organização sindical que integre.

■ GABARITO ■

1. “d”. Cf., na sequência das alternativas, art. 7.º, XXXIII, XVIII, XIV, XXXII, XXIX. Sem dúvida, questão que exigia o conhecimento da “letra da lei”, como vem sendo visto em algumas provas. Dessa forma, sugerimos ao amigo leitor que faça um estudo detido dos referidos incisos.
2. “certo”. Cf., no <i>item 13.7.9</i> , o entendimento do STF no sentido de proibição do exercício do direito de greve em relação a alguns serviços públicos que, em razão de sua essencialidade para a sociedade, deverão ser prestados em sua totalidade (Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, j. 20.05.2009, Plenário, DJE de 25.09.2009).
3. “certo”.
4. “a”.
5. “a”. Cf. art. 7.º, XVI, VI, IX e XIII.
6. “b”. Cf. art. 7.º, I, XI, XII, XIII e XXVIII.
7. “c”. Cf. art. 7.º, XII. A <i>letra “a”</i> está errada, pois, nos termos do art. 7.º, XIV, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo

negociação coletiva. A letra “b” está errada, pois, nos termos do art. 7.º, XVI, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. A letra “d” está errada porque, segundo o art. 7.º, XI, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. A letra “e” está errada, já que a teor do art. 11, somente nas empresas de mais de 200 empregados é que está assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

8. “c”, conforme o art. 7.º, VI, da CF/88. A letra “a” está errada porque viola a literalidade do art. 7.º, XIII, que estabelece serem direitos dos trabalhadores duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A letra “b” está errada por violar o art. 7.º, XXVIII — “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. A letra “d” está errada. De acordo com o art. 7.º, XI, são direitos dos trabalhadores a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Assim, a *participação na gestão da empresa* não é regra e dependerá de lei definindo os seus termos. A letra “e” está errada por violar a literalidade do art. 6.º da CF/88, que tem a seguinte redação: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (cf. EC n. 64/2010).

9. “e”, conforme o art. 8.º, VII, da CF/88. Estamos diante de típica questão que exigia a memorização da “letra da lei”. Então, vamos à análise. A letra “a” está errada porque a definição, segundo o art. 9.º, § 1.º, dar-se-á de acordo com a lei e não a critério do sindicato. A letra “b” está **errada por violar o art. 7.º, XXVII** — “proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos”. A letra “c” está errada por violar o art. 7.º, XXXIII — “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”. A letra “d” está errada uma vez que viola a literalidade do art. 8.º, II — “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.

10. “e”. <i>Vide</i> parte teórica, <i>itens 15.5.1 e 15.5.2.</i>
11. “b”.
12. “errado”. <i>Vide</i> parte teórica, <i>itens 15.5.1 e 15.5.2.</i>
13. “errado”.
14. “e”, conforme a literalidade do art. 11 da CF/88.
15. “certo”.
16. “a”, conforme a literalidade do art. 8.º, I, da CF/88.
17. “e”, consoante a literalidade do art. 8.º, VII, da CF/88.
18. “certo”, nos termos do art. 8.º, VI, da CF/88.
19. “certo”. Confira parte teórica, <i>item 15.4.1.</i>
20. “d”. A letra “a” está prevista no art. 7.º, XXXI; a letra “b” no art. 7.º, I; a letra “c” no art. 7.º, II; a letra “e” no art. 7.º, VII. Em relação à letra “d”, a Constituição apenas estabelece o FGTS como direito dos trabalhadores (art. 7.º, III), mas não quando ele não será devido. A sua regulamentação foi definida pela legislação.
21. “certo”. Art. 8.º, VI, da CF/88.
22. “errado”. Art. 8.º, VII, da CF/88.

NACIONALIDADE

■ 16.1. CONCEITO

Nacionalidade pode ser definida como o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse Estado e, por consequência, desfrute de direitos e submeta-se a obrigações.

■ 16.1.1. Definições correlatas

■ **povo:** conjunto de pessoas que fazem parte do Estado — o seu elemento humano —, unido ao Estado pelo vínculo jurídico-político da nacionalidade;

■ **população:** conjunto de **residentes** no **território**, sejam eles **nacionais** ou **estrangeiros** (bem como os **apátridas** ou *heimatlos* — expressão alemã);

■ **nação:** conjunto de pessoas nascidas em um território, ladeadas pela mesma língua, cultura, costumes, tradições, adquirindo uma mesma identidade sociocultural. São os **nacionais**, distintos dos **estrangeiros**. **São os brasileiros natos ou naturalizados;**

■ **nacionalidade:** como vimos, é o **vínculo jurídico-político** que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse Estado e, por consequência, desfrute de direitos e

submeta-se a obrigações. Como diria Pontes de Miranda, a nacionalidade faz da pessoa um dos **elementos componentes da dimensão pessoal do Estado**;

■ **cidadania**: tem por pressuposto a nacionalidade (que é mais ampla que a cidadania), caracterizando-se como a **titularidade** de direitos políticos de votar e ser votado.¹ O **cidadão**, portanto, nada mais é que o nacional (brasileiro nato ou naturalizado) que goza de direitos políticos.

■ 16.2. ESPÉCIES DE NACIONALIDADE E CRITÉRIOS PARA A SUA AQUISIÇÃO

A doutrina costuma distinguir a nacionalidade em duas espécies: a) **primária** ou **originária** (involuntária); b) **secundária** ou **adquirida** (voluntária).

A **nacionalidade primária** é imposta, de maneira unilateral, independentemente da vontade do indivíduo, pelo Estado, no momento do **nascimento**. Falamos em involuntariedade porque, de maneira soberana, cada país estabelece as regras ou critérios para a outorga da nacionalidade aos que nascerem sob o seu governo.

Alguns adotam o critério do ***ius sanguinis***, ou seja, o que interessa para a aquisição da nacionalidade é o sangue, a filiação, a ascendência, pouco importando o local onde o indivíduo nasceu. (Em geral o critério do *ius sanguinis* é utilizado por países de emigração, a fim de se manter o vínculo com os descendentes, como ocorre com a maior parte dos países europeus.)

Outros adotam o critério do ***ius solis***, ou **critério da territorialidade**, vale dizer, o que importa para a definição e aquisição da nacionalidade é o **local do nascimento**, e não a descendência. (Esse critério é normalmente utilizado pelos países de imigração, a fim de que os descendentes dos imigrantes, que venham a nascer no solo do novo país, sejam nacionais desse novo país, e não do de origem, o que ocorreria se o critério fosse o do sangue.)

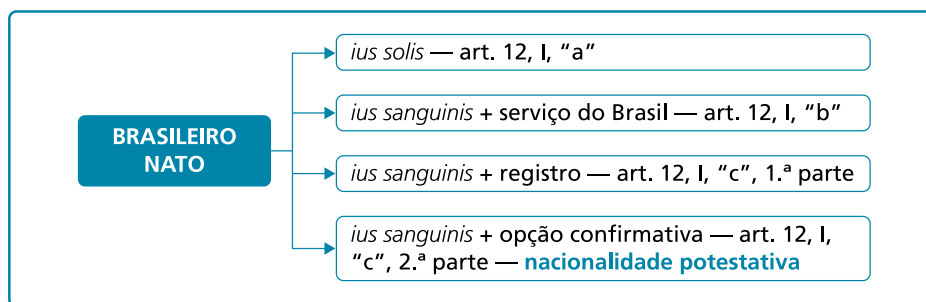
Já a **nacionalidade secundária** é aquela que se adquire por vontade própria, depois do nascimento, normalmente pela **naturalização**, que poderá ser requerida tanto pelos **estrangeiros** como pelos **heimatlos (apátridas)**, ou seja,

aqueles indivíduos que não têm pátria alguma. O estrangeiro, dependendo das regras de seu país, poderá ser enquadrado na categoria de **polipátrida** (**multinacionalidade** — ex.: filhos de italiano — critério do sangue — nascidos no Brasil — critério da territorialidade).

Surge, então, o chamado **conflito de nacionalidade**: a) **positivo** — polipátrida (multinacionalidade) e b) **negativo** — apátrida, intolerável, especialmente diante do art. XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948),² que assegura a toda pessoa o direito a uma nacionalidade, proibindo que seja arbitrariamente dela privada, ou impedida de mudá-la.

■ 16.3. BRASILEIRO NATO

Como regra geral prevista no art. 12, I, o Brasil, país de imigração, adotou o critério do *ius solis*. Essa regra, porém, é atenuada em diversas situações, ou “temperada” por outros critérios, como veremos. Lembrar que o art. 12, I, traz hipóteses taxativas de previsão de aquisição da nacionalidade brasileira. Assim, serão brasileiros natos:



■ ***ius solis* (art. 12, I, “a”)**: qualquer pessoa que nascer no **território brasileiro**³ (República Federativa do Brasil), mesmo que seja filho de pais estrangeiros. Os pais estrangeiros, no entanto, não podem estar a serviço de seu país. Se estiverem, o que podemos afirmar é que o indivíduo que nasceu em território brasileiro não será brasileiro nato. Se será nacional de seu país, não sabemos. Devemos analisar, e sempre, as regras do direito estrangeiro;

■ ***ius sanguinis* + serviço do Brasil (art. 12, I, “b”)**: e se o nascimento

se der fora do Brasil? Serão considerados brasileiros natos os que, mesmo tendo nascido no estrangeiro, sejam filhos de pai ou mãe brasileiros e qualquer deles (o pai, a mãe, ou ambos) esteja a serviço da República Federativa do Brasil (administração direta ou indireta);

Interessante observar que o art. 12, I, “b”, estabelece como premissa o pai ou a mãe ser **brasileiro** e não exige que seja brasileiro nato. Assim, entendemos que, como a regra geral estabelece a impossibilidade de se estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 2.º, cf. *item 16.6*), o filho, brasileiro **nato**, poderá ser tanto de pai brasileiro, seja nato ou naturalizado, como de mãe brasileira nata ou mesmo naturalizada.

Segundo anotam Mendes, Coelho e Branco, “a expressão *a serviço do Brasil* há de ser entendida não só como a atividade diplomática afeta ao Poder Executivo, mas também como qualquer função associada às atividades da União, dos Estados ou dos Municípios ou de suas autarquias. Rezek observa que configura ‘a serviço do Brasil’, para os fins da norma constitucional, o serviço prestado a organização internacional de que a República faça parte, independentemente de o agente ter sido designado ou não pelos órgãos governamentais brasileiros”.⁴

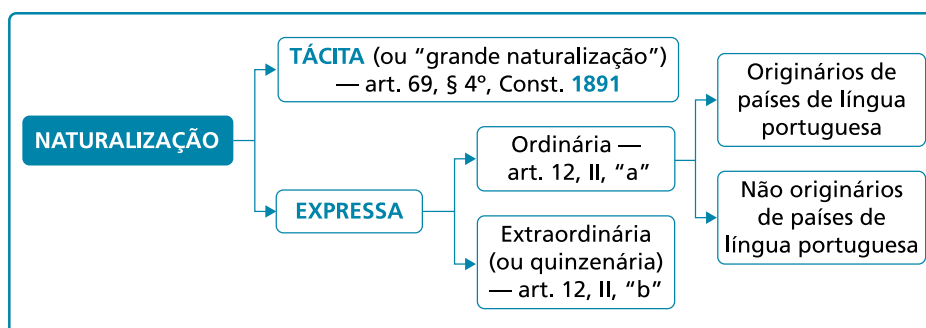
■ ***ius sanguinis* + registro (art. 12, I, “c”, primeira parte):** e se o nascimento não ocorrer no Brasil, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira (natos ou naturalizados) e os pais não estiverem a serviço do país? Ex.: Maria, em férias no Japão, tem o seu filho em Tóquio. Pergunta-se: o filho de Maria será considerado japonês? Depende da regra daquele país. E brasileiro? Nesse caso, corrigindo a imperfeição trazida pela ECR n. 3/94, a **EC n. 54/2007** (fruto de conversão da denominada “PEC dos brasileirinhos apátridas”), resgatando a regra anterior, estabeleceu a possibilidade de aquisição da nacionalidade brasileira originária pelo simples ato de **registro em repartição brasileira competente** e, assim, resolvendo um grave problema dos apátridas.

■ ***ius sanguinis* + opção confirmativa (art. 12, I, “c”, segunda parte):** outra possibilidade de aquisição da nacionalidade brasileira, mantida pela **EC n. 54/2007**, dá-se quando o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira

(natos ou naturalizados), que não estejam a serviço do Brasil, vier a residir no Brasil e optar, em qualquer tempo, **depois de atingida a maioridade**, pela nacionalidade brasileira. Trata-se da chamada **nacionalidade potestativa**, uma vez que a aquisição depende da exclusiva vontade do filho. [5](#)

■ 16.4. BRASILEIRO NATURALIZADO

■ 16.4.1. Noções introdutórias: procedimento



Como forma de aquisição da **nacionalidade secundária**, a Constituição prevê o processo de naturalização, que dependerá tanto da manifestação de vontade do interessado como da aquiescência estatal, que, através de ato de soberania, de forma discricionária, poderá ou não atender à solicitação do estrangeiro ou apátrida.

Dessa maneira, não mais se prevê a naturalização tácita (grande naturalização), como aconteceu na vigência da Constituição de 1891. [6](#) A CF/88 somente estabeleceu a **naturalização expressa**, que se divide em **ordinária** e **extraordinária (quinzenária)**.

Nos termos do art. 115 do *Estatuto dos Estrangeiros* (Lei n. 6.815/80), aquele que pretender a naturalização deverá requerê-la ao **Ministro da Justiça**, declarando nome por extenso, naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de nascimento, profissão, lugares onde haja residido anteriormente no Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito a que alude o art. 112, item VII, e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome à língua

portuguesa, devendo a petição ser assinada pelo naturalizando e instruída com os documentos e demais formalidades especificados no Regulamento (Decreto n. 86.715/81).

A concessão da naturalização será faculdade exclusiva do Poder Executivo e far-se-á mediante **portaria do Ministro da Justiça** (art. 111 da Lei n. 6.815/80).

Assim que for publicada no *Diário Oficial*, a *portaria de naturalização* será arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá **certificado** relativo a cada naturalizando, o qual será solenemente entregue, na forma fixada no Regulamento, pelo **juiz federal** da cidade onde tenha domicílio o interessado.

Quando não houver juiz federal na cidade em que tiverem domicílio os interessados, a entrega será feita pelo juiz ordinário da comarca e, na sua falta, pelo da comarca mais próxima.

Por esse motivo, o **art. 109, X, da CF/88** estabelece ser competência dos juízes federais processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o *exequatur*, e de sentença estrangeira, após a homologação, as **causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização**.⁷

■ 16.4.2. Naturalização ordinária

■ **estrangeiros não originários de países de língua portuguesa e apátridas (art. 12, II, “a”, primeira parte):** naturalizar-se-ão brasileiros de acordo com os critérios definidos em lei, no caso, desde que preenchidas as regras do art. 112 do Estatuto dos Estrangeiros — Lei n. 6.815, de 19.08.1980;⁸

■ **originários de países de língua portuguesa⁹ (art. 12, II, “a”, segunda parte):** a) residência por um ano ininterrupto e b) idoneidade moral.

■ 16.4.3. Naturalização extraordinária ou quinzenária

Prevista no art. 12, II, “b”, a naturalização extraordinária ou quinzenária dar-se-á quando os estrangeiros, de **qualquer nacionalidade**, residentes na República Federativa do Brasil **há mais de 15 anos**¹⁰ **ininterruptos**¹¹ e **sem condenação penal**, requisitarem a nacionalidade brasileira.

A naturalização extraordinária é “intransferível”, vale dizer, só a adquire aquele que preencher os requisitos constitucionais. Como muito bem lembra José Afonso da Silva, “a naturalização não importa a aquisição da nacionalidade brasileira pelo cônjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza estes a entrar ou radicar-se no Brasil, sem que satisfaçam as exigências legais”.¹²

■ 16.4.4. Radicação precoce e conclusão de curso superior?

Essas outras duas hipóteses de naturalização (brasileiros naturalizados) estavam expressamente previstas na CF/67 (art. 140, II, “b”, 1 e 2) e na EC n. 1/69 (art. 145, II, “b”, n. 2), nos seguintes termos, respectivamente:

■ **radicação precoce:** “os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos no Brasil durante os primeiros cinco anos de vida, radicados definitivamente no território nacional. Para preservar a nacionalidade brasileira, deverão manifestar-se por ela, inequivocamente, até dois anos após atingir a maioridade”;

■ **conclusão de curso superior:** “os nascidos no estrangeiro que, vindo residir no País antes de atingida a maioridade, façam curso superior em estabelecimento nacional e requeiram a nacionalidade até um ano depois da formatura”.

Apesar de o texto constitucional de 1988 não mais tratar, expressamente, das aludidas hipóteses de naturalização, elas ainda **subsistem**, encontrando o seu fundamento constitucional no art. 12, II, “a”, primeira parte, qual seja, os que, **na forma da lei** (Lei n. 6.815/80), se naturalizarem brasileiros. Como já visto, a lei é o Estatuto dos Estrangeiros, que, em seus arts. 115, § 2.º, I e II, e 116, expressamente descreve as hipóteses de naturalização por **radicação precoce** e **conclusão de curso superior**.

■ 16.5. QUASE NACIONALIDADE — PORTUGUESES — ART. 12, § 1.º — RECIPROCIDADE

Os **portugueses**, como originários de país de língua portuguesa, enquadram-se na regra do art. 12, II, “a”, ou seja, podem naturalizar-se brasileiros bastando que tenham residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

Outrossim, temos a hipótese dos portugueses com residência permanente no Brasil que queiram continuar com a nacionalidade portuguesa (estrangeiros) e não façam a opção pela naturalização brasileira.

Havendo **reciprocidade** em favor de brasileiros, serão atribuídos aos portugueses com residência permanente no Brasil os mesmos **direitos** inerentes ao brasileiro, salvo os casos em que houver expressa vedação constitucional.

Observar que os portugueses não perdem a sua cidadania. Continuam sendo portugueses, estrangeiros, portanto, no Brasil, mas podendo exercer os direitos conferidos aos brasileiros, desde que não sejam vedados (ex.: art. 12, § 3.º) e haja, como visto, a reciprocidade para brasileiros em Portugal.

Trata-se da chamada **cláusula de reciprocidade** (*do ut des*), assegurada pelo *Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa*, celebrado em Porto Seguro em 22.04.2000 (**Decreto n. 3.927, de 19.09.2001**).

O STF confirma a importância do referido acordo bilateral entre Brasil e Portugal: “a norma inscrita no art. 12, § 1.º, da Constituição da República — que contempla, em seu texto, hipótese excepcional de **quase nacionalidade** — não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficaz, seja no que se refere a todas as consequências jurídicas que dela derivam, pois, para incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende, ainda, de requerimento do súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de **preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses**” (Ext 890, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05.08.2004, *DJ* de 28.10.2004).

■ 16.6. A LEI PODERÁ ESTABELECEER DISTINÇÕES ENTRE BRASILEIROS NATOS E NATURALIZADOS?

■ 16.6.1. Regra geral

De maneira coerente com o **princípio da igualdade** (isonomia), a CF vedou qualquer possibilidade de se estabelecer por lei distinção entre brasileiros natos e naturalizados, ressalvados os casos previstos pela própria Constituição (art. 12, § 2.º).

Assim: **regra geral** não se pode diferenciar o brasileiro nato do naturalizado. A diferenciação poderá ser feita somente nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição, quais sejam:

■ Art. 5.º, LI
■ Art. 12, § 3.º
■ Art. 12, § 4.º, I
■ Art. 89, VII
■ Art. 222

■ 16.6.2. Hipóteses taxativas de exceção à regra geral

■ 16.6.2.1. Extradicação

O tema da extradicação merece algum comentário, em razão de suas peculiaridades, distinguindo-o da **expulsão, deportação, banimento, asilo**

político e **refúgio**, e deve ser aprofundado nos livros de *Direito Internacional Público*.

Segundo Accioly, Nascimento e Silva e Casella, “extradição é o ato mediante o qual um estado entrega a outro estado indivíduo acusado de haver cometido crime de certa gravidade ou que já se acha condenado por aquele, após haver-se certificado de que os direitos humanos do extraditando serão garantidos. A instituição da extradição tem por objetivo principal evitar, mediante a cooperação internacional, que um indivíduo deixe de pagar pelas consequências de crime cometido. Atualmente, a extradição procura garantir ao acusado um julgamento justo, de conformidade com o art. XIX da *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, segundo o qual ‘Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa’”. [13](#)

Dessa forma, podemos identificar tanto a *extradição ativa* como a *passiva*.

- **extradição ativa:** o requerimento de entrega é feito pelo Brasil ao Estado estrangeiro;

- **extradição passiva:** o requerimento de entrega é formalizado pelo Estado estrangeiro ao Estado brasileiro.

■ 16.6.2.1.1. *Extradição ativa*

Ao tratar da **extradição ativa** (aquela em que o **Estado brasileiro solicita** a Estado estrangeiro a entrega de indivíduo), o art. 20, *caput*, do **Decreto-lei n. 394/38** estabelece que, quando se tratar de indivíduo reclamado pela justiça brasileira e refugiado em país estrangeiro, o pedido de extradição deverá ser transmitido ao Ministério da Justiça, que o examinará e, se o julgar procedente, encaminhará ao Ministério das Relações Exteriores para formalização da solicitação (cf. **Ext 1.011**, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, j. 10.10.2005, *DJ* de 25.10.2005).

O STF, portanto, não tem papel ativo nesse processo de extradição e, assim,

no caso, o Ministério da Justiça não precisa de autorização da Corte para pedir a extradição.

Esse entendimento foi confirmado pelo Min. Joaquim Barbosa no caso do ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado no processo do mensalão (AP 470) e que estava foragido, tendo sido preso na Itália em 05.02.2014.

Ficou acertado que o pedido de extradição ativa seria providenciado pela PGR ao Ministério da Justiça, que tomaria as medidas cabíveis, tendo em vista que as relações extradicionais se estabelecem entre o Brasil e a Itália, nos termos de tratado bilateral assinado entre os dois países.

Feito o pedido de extradição pelo governo brasileiro, em um primeiro momento, a primeira instância da Justiça Italiana (*Corte de Bolonha*) o negou, sob o fundamento de falta de estrutura dos presídios brasileiros. Em 12.02.2015, contudo, a *Corte de Cassação de Roma* autorizou a extradição, revertendo a decisão anterior. O *Ministro de Justiça da Itália*, em 24.04.2015, decidiu no sentido do envio de Pizzolato para o Brasil. Estando tudo certo para a extradição, a sua defesa apresentou recurso para o *Tribunal Administrativo Regional — TAR de Roma* contra o ato do Ministro da Justiça italiano, requerendo que o cumprimento de pena fosse na Itália. Rejeitado o recurso (j. 04.06.2015), aguarda-se a palavra final pelo *Conselho de Estado da Itália* (pendente no fechamento desta edição em 20.06.2015).

■ 16.6.2.1.2. **Extradição passiva: brasileiro nato x brasileiro naturalizado**

De acordo com o art. 5.º, LI, o **brasileiro nato** nunca poderá ser extraditado (estamos nos referindo à extradição passiva¹⁴). Já o **naturalizado** poderá ser extraditado em duas situações:

■ **crime comum:** o naturalizado poderá ser extraditado somente se praticou o crime comum **antes** da naturalização;

■ **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins:** no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas

afins, **na forma da lei**, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado, não importando o momento da prática do fato típico, seja antes, seja depois da naturalização.

Estamos diante do **princípio geral de inextraditabilidade do brasileiro** que, contudo, em relação ao **naturalizado**, foram estabelecidas duas exceções:

- “a primeira, de **eficácia plena e aplicabilidade imediata**, se a naturalização é posterior ao crime comum pelo qual procurado”;

- “a segunda (de **eficácia limitada, aplicabilidade mediata e reduzida**, acrescente-se), no caso de naturalização anterior ao fato, se se cuida de tráfico de entorpecentes: aí, porém, admitida, não como a de qualquer estrangeiro, mas, sim, **‘na forma da lei’**, e por **‘comprovado envolvimento’** no crime: a essas exigências de caráter excepcional não basta a concorrência dos requisitos formais de toda extradição, quais sejam, a dúplice incriminação do fato imputado e o juízo estrangeiro sobre a seriedade da suspeita. (...); para a extradição do brasileiro naturalizado antes do fato, porém, que só a autoriza no caso de seu ‘comprovado envolvimento’ no tráfico de drogas, a Constituição impõe à lei ordinária a criação de um procedimento específico, que comporte a cognição mais ampla da acusação na medida necessária à aferição da concorrência do pressuposto de mérito, a que excepcionalmente subordinou a procedência do pedido extraditório: por isso, a norma final do art. 5.º, LI, CF, não é regra de eficácia plena, nem de aplicabilidade imediata” (Ext 541 — Rel. p/ o ac. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07.11.91, Plenário, *DJ* de 18.12.92 e Ext 934-QO, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.09.2004, Plenário, *DJ* de 12.11.2004).

A regra segundo a qual o **brasileiro nato** nunca poderá ser extraditado decorre da ideia de **soberania**, preservação da jurisdição nacional, incluindo “a eventual parcialidade dos tribunais estrangeiros e as condições das instituições penais de inúmeros países”.

Contudo, afirmam Accioly, Nascimento e Silva e Casella: “... parece-nos inadmissível que indivíduos acusados de crimes hediondos, como sequestro, tráfico de entorpecentes, estupro, limpeza étnica, genocídio e crimes contra a humanidade, possam merecer proteção de seu país”. [15](#)

O **naturalizado**, por sua vez, e conforme vimos, poderá ser extraditado se praticou crime comum antes da naturalização, ou, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, se praticado antes ou depois da naturalização.

O **estrangeiro** só **não** poderá ser extraditado por **crime político** ou de **opinião** (art. 5.º, LII).

■ 16.6.2.1.3. *Extradição passiva: regras procedimentais*

O procedimento da **extradição passiva** (aquela pela qual **Estado estrangeiro** solicita ao Estado brasileiro a entrega de determinada pessoa acusada ou já condenada por ter cometido crime) está previsto, basicamente, no **Estatuto dos Estrangeiros (Lei n. 6.815/80)** e no **RI/STF**, que deverão adequar-se ao balizamento dos incisos **LI** e **LII** do **art. 5.º da Constituição Federal**.

De acordo com o **art. 78** da Lei n. 6.815/80, são condições para concessão da extradição: **a)** ter sido o crime cometido no **território do Estado requerente** ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; **b)** existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado requerente, salvo o disposto no art. 82 da referida lei.

Assim, a **extradição passiva** poderá ter tanto **caráter instrutório** como **executório**. No primeiro caso (*extradição instrutória*), desde que exista ordem de prisão emanada de autoridade competente do Estado requerente, admite-se a extradição mesmo diante da mera existência de procedimento persecutório instaurado no exterior.¹⁶ Na segunda hipótese (*extradição executória*), o pedido de extradição pressupõe a existência de sentença penal condenatória (Ext 652, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.1996, Plenário, *DJE* de 21.11.2008).

De acordo com o art. 80 do Estatuto dos Estrangeiros, na redação dada pela **Lei n. 12.878/2013**, a extradição será **requerida por via diplomática** ou, quando previsto em tratado, **diretamente ao Ministério da Justiça**, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica, ou a certidão da sentença condenatória, ou decisão penal proferida por juiz ou autoridade competente.

O pedido deverá ser instruído com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso, a identidade do extraditando e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e sua prescrição.

O encaminhamento do pedido pelo Ministério da Justiça ou por via diplomática confere autenticidade aos documentos, que serão acompanhados de versão feita oficialmente para o idioma oficial da República Federativa do Brasil, qual seja, a língua portuguesa.

O **pedido**, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou em tratado, **será encaminhado pelo Ministério da Justiça ao STF**.

Não preenchidos os pressupostos de que trata o *caput* do art. 81 da Lei n. 6.815/80, o pedido será **arquivado** mediante decisão fundamentada do Ministro de Estado da Justiça, sem prejuízo de sua renovação, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado.

De acordo com o art. 102, I, “g”, da CF/88, a **competência** para **julgar** originariamente a **extradição** solicitada por Estado estrangeiro é do **STF**. A partir da edição da *emenda regimental n. 45/2011*, que alterou os arts. 6.º, I, “f”, e 9.º, I, “h”, do RI/STF, a atribuição deixou de ser do Plenário e passou a ser das **Turmas** (conforme já apontamos, dentro da ideia de efetividade do processo e racionalização, observa-se, cada vez mais, a ampliação da competência das Turmas).

Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja **preso** e colocado à disposição do Tribunal (art. 208 do RI/STF).

Referida prisão pode ser caracterizada como um **pressuposto do processo de extradição** e não se confunde com as prisões cautelares do CPP. Trata-se de prisão a ser **decretada** pelo **Ministro Relator¹⁷** do processo extradicional que tramita de modo originário no **STF**, no caso, nos termos do art. 5.º, LXI, da CF/88, a **autoridade judiciária competente**.

Como muito bem anotou o Min. Celso de Mello, “**nenhum pedido de extradição terá andamento sem que o extraditando seja preso e colocado à**

disposição do STF. Essa prisão de **natureza cautelar** destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.7.1993, Plenário, *DJ* de 10.09.1993).

Nesse sentido, a **Lei n. 12.878/2013**, alterando a redação do art. 82 do Estatuto dos Estrangeiros (Lei n. 6.815/80), trouxe nova disciplina em relação à **prisão cautelar para fins de extradição**.

De acordo com a regra, o Estado interessado na extradição poderá, em caso de urgência e antes da formalização do pedido de extradição, ou conjuntamente com este, **requerer a prisão cautelar** do extraditando por via diplomática ou, quando previsto em tratado, ao Ministério da Justiça, que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nessa Lei ou em tratado, representará ao Supremo Tribunal Federal **(conforme se apontou, a autoridade competente para se decretar a prisão é o Ministro do STF)**.

O pedido de prisão cautelar noticiará o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.

O pedido de prisão cautelar poderá ser apresentado ao Ministério da Justiça por meio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro.

O Estado estrangeiro deverá, no prazo de 90 dias contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando, formalizar o pedido de extradição, sob pena de o extraditando ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição haja sido devidamente requerida.

Deixamos claro que a **competência originária** do **STF** é para o julgamento de **extradição solicitada por Estado estrangeiro**, ou seja, a **extradição passiva**, inadmitindo, nesse sentido, a extradição ativa, que, conforme visto, deverá dar-se pelas vias diplomáticas e entre Estados soberanos. [18](#)

■ 16.6.2.1.4. *Extradição passiva: vedações legais*

O Estatuto dos Estrangeiros (Lei n. 6.815/80), em seu **art. 91**, **veda** a efetiva entrega do extraditando se o Estado estrangeiro não assumir o compromisso diplomático formal de:

■ não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido (**princípio da especialidade** ou do **efeito limitativo da extradição**,¹⁹ **que não é absoluto** diante da possibilidade de haver **pedido de extensão** pelo Estado estrangeiro e com ele o Brasil **expressamente concordar**);

■ computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição (**detração penal**);

■ **comutar** em pena privativa de liberdade (atualmente art. 75 do Código Penal), não superior a 30 anos de cárcere) a pena de prisão perpétua ou de morte,²⁰ ressalvados, quanto à última, os casos em que a lei brasileira permitir a sua aplicação, ou seja, somente em caso de guerra declarada (cf. **Ext. 855**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.08.2004, Plenário, *DJ* de 1.º.07.2005, que fixou a nova orientação da Corte);

■ não ser o extraditando entregue, sem o consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame;

■ não considerar qualquer motivo político para agravar a pena.

O art. 76 da Lei n. 6.815/80 estabelece que a extradição **poderá** ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.

O art. 77, por sua vez, **veda** a concessão da extradição, além das hipóteses já estudadas, quando:

■ o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, devendo, portanto, ser respeitado o **princípio da dupla tipicidade**. Ou seja, o fato **tem** de ser considerado **crime** tanto no **Brasil** como no **Estado requerente**, interessando a conduta praticada mesmo que não haja identidade de designação formal do tipo penal.²¹ Assim, por

exemplo, se a conduta não é considerada crime no Brasil, por se tratar de conduta lícita, ou mesmo, mera contravenção penal, vedada estará a extradição para o Estado estrangeiro;

- o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;

- a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 1 ano;

- o extraditando responder a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;

- estiver extinta a punibilidade pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Ou seja, para que possa ser autorizada a extradição é indispensável a observância do **princípio da dupla punibilidade**;

- o fato constituir crime político;[22](#)

- o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção.

■ **16.6.2.1.5. Extradição passiva: e se o extraditando for casado com brasileira ou tiver filho brasileiro? Haverá óbice, por esse motivo, ao pedido de extradição?**

Não.

Essa dúvida surge em razão da tentativa de se aplicar por analogia a regra explícita prevista no art. 75, II, “a” e “b”, da Lei n. 6.815/80, que impede a **expulsão** (e veja, o texto fala em **expulsão**, e não em extradição) quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos; ou filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente (cf. discussão no *item 16.6.2.1.7*).

Conforme pacificou a Corte, “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro” (**S. 421/STF**). Esse

entendimento, firmado em 1964, ainda persiste no Plenário do STF. Vejamos:

“A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência *more uxorio* do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. (...) **Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que, com esta, possua filho brasileiro.** A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de **cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum**, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (**Ext 1.201**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17.02.2011, Plenário, *DJE de 15.03.2011*). No mesmo sentido, cf. **Ext 1.252**, j. 08.05.2012).

■ **16.6.2.1.6. Extradição passiva: entendendo o STF pela procedência do pedido de extradição, o Presidente da República será obrigado a extraditar o requisitado?**

Não. O Presidente da República terá **discricionariedade**.

O *Estatuto dos Estrangeiros* estabeleceu alguns parâmetros para a decisão do Presidente da República e, assim, presentes os requisitos legais acima expostos (e que vedam a extradição), ele poderia **negá-la**, até diante da ideia de **soberania**, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1.º, I).

Outro ponto seria se não presentes os requisitos legais que vedam a extradição. Nesse caso, conforme indagado acima, poderia o Presidente da República ir contra a decisão do STF?

A questão foi amplamente examinada na **Ext 1.085**, julgada em 18.11.2009 pelo STF, [23](#) na qual se discutiu o pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália contra nacional italiano, o ex-ativista *Cesare Battisti*, que havia sido condenado à pena de prisão perpétua pela prática de quatro homicídios naquele país, quando era integrante do grupo guerrilheiro *Proletários Armados pelo*

Comunismo (PAC).

Battisti fugiu da Itália, foi para a França, depois veio para o Brasil, onde conseguiu a condição de **refugiado**.

Nos termos do art. 1.º da Lei n. 9.474/97, será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

- devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
- não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;
- devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

Diante do pedido de extradição, em 2007 *Battisti* foi recolhido preso, e a questão passou a ser examinada pela Corte.

Resolvendo questão preliminar, o STF analisou “... a concessão do *status* de refugiado ao extraditando pelo Ministro da Justiça, concluindo pela ilegalidade e pela ineficácia desse ato. Asseverou que, não obstante a Corte, em princípio e incidentalmente, houvesse declarado, no julgamento da Ext 1.008/Governo da Colômbia (*DJE* de 17.8.2007), a constitucionalidade do art. 33 da Lei n. 9.474/97 (‘o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio’), e independentemente da estima do acerto, ou não, dessa decisão, destacou que ficariam por esclarecer as condições em que a outorga de refúgio extinguiria o processo de extradição. No ponto, ressaltou que, apesar de reconhecido, naquele julgado, o **caráter político-administrativo** da decisão concessiva de refúgio, revendo os termos e o alcance da lei, à luz sistêmica da ordem jurídica, aduziu que tal afirmação não poderia ser entendida em acepção demasiado estrita, nem que o fato de o poder ou dever de outorga ser atribuição reservada à competência própria da União, por representar o país nas relações

internacionais, lhe subtrairia, de forma absoluta, os respectivos atos jurídico-administrativos ao ordinário controle jurisdicional de legalidade (*judicial review*)” (Inf. 558/STF).

Superada essa questão, em votação apertada (5 x 4, não estando presente toda a composição da Corte, o que, em tese, significa que o entendimento ainda pode ser revisto em julgamentos futuros), o STF decidiu que os atos praticados por *Cesare Battisti* não tiveram conotação política (pois, se fosse outro o entendimento, a extradição estaria inviabilizada pelo art. 5.º, LII) e, então, deferiu o pedido formulado pelo governo italiano.

Segundo decidiram os Ministros, “**não configura crime político**, para fim de obstar o acolhimento de pedido de extradição, homicídio praticado por membro de organização revolucionária clandestina, em plena **normalidade institucional** de Estado Democrático de Direito, sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação legítima a regime opressivo” (*item 3 da Ementa*).

Logo, declarou o STF que os crimes praticados eram de natureza **comum**, não estavam prescritos e não havia nenhuma violação ao *Estatuto dos Estrangeiros*, bem como ao *Tratado de Extradição* firmado entre Brasil e Itália, tudo na linha do voto do Min. Cezar Peluso, relator.

Continuando o julgamento, também pela mesma votação apertada de 5 x 4, o STF, em um primeiro momento, proclamou o resultado no sentido de o Presidente da República não estar obrigado a proceder à extradição (entrega), podendo decidir, nos termos do art. 84, VII, de modo *discrecionário*.

Contudo, em **16.12.2009**, o Plenário do STF, apreciando questão de ordem apresentada pelo governo italiano em relação ao voto do Min. Eros Grau, **retificou** a **proclamação do resultado**, determinando, agora por votação **majoritária**, que o Presidente deve decidir a extradição com base no tratado bilateral com a Itália e a lei.

Assim, o Presidente da República não está vinculado à decisão do STF. Porém, deve observar os termos do *direito convencional*, **não** sendo, portanto, nesse ponto, **discrecionário** o seu ato, porque, repita-se, **balizado pelas disposições do tratado**.

Nesse sentido, conforme o voto do Min. Eros Grau: “2. Ao Supremo Tribunal Federal cabe processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, ‘g’, da Constituição do Brasil). Lê-se na ementa da **Extradição 272**, relator o ministro Victor Nunes Leal, o seguinte: ‘Extradição, a) o deferimento ou recusa da extradição é direito inerente à soberania. b) A efetivação, pelo governo, da entrega de extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal, depende do direito internacional convencional’. No voto que então proferiu, o ministro Victor Nunes Leal observou: ‘Mesmo que o Tribunal consinta na extradição — por ser regular o pedido —, surge outro problema, que interessa particularmente ao Executivo: saber se ele está obrigado a efetivá-la. Parece-me que essa obrigação só existe nos limites do direito convencional, porque não há, como diz Mercier, ‘um direito internacional geral de extradição’”.[24](#)

Esse parece ser, em sede doutrinária, o entendimento de Rezek: “fundada em promessa de reciprocidade, a demanda extradicional abre ao governo brasileiro a perspectiva de uma *recusa sumária*, cuja oportunidade será mais tarde examinada. Apoiada, **porém**, que se encontre em **tratado**, o pedido **não comporta semelhante recusa**. Há, neste passo, um **compromisso** que ao governo brasileiro incumbe **honrar**, sob pena de ver colocada em causa sua **responsabilidade internacional**. É claro, não obstante, que o compromisso tão somente priva o governo de qualquer arbítrio, determinando-lhe que submeta ao Supremo Tribunal Federal a demanda, e obrigando-o a efetivar a extradição pela corte entendida legítima, desde que o Estado requerente se prontifique, por seu turno, ao atendimento dos requisitos de *entrega* do extraditando...”.[25](#)

O ex-Presidente da República *Luiz Inácio Lula da Silva*, no final de seu mandato, no dia **30.12.2010**,[26](#) com base em *parecer* da AGU, decidiu não extraditar *Battisti*, segundo nota lida pelo então Ministro das Relações Exteriores, *Celso Amorim*:

“O Presidente da República tomou hoje a decisão de não conceder extradição ao cidadão italiano Cesare Battisti, com base em parecer da Advocacia-Geral da União. O parecer considerou atentamente todas as cláusulas do Tratado de

Extradição entre o Brasil e a Itália, em particular a disposição expressa na letra ‘f’, do item 1, do artigo 3 do Tratado, que cita, entre as **motivações** para a não extradição, a **condição pessoal do extraditando**. Conforme se depreende do próprio Tratado, esse tipo de juízo não constitui afronta de um Estado ao outro, uma vez que situações particulares ao indivíduo podem gerar riscos, a despeito do caráter democrático de ambos os Estados. Ao mesmo tempo, o Governo brasileiro manifesta sua profunda estranheza com os termos da nota da Presidência do Conselho dos Ministros da Itália, de 30 de dezembro de 2010, em particular com a impertinente referência pessoal ao Presidente da República”.

Diante desse fato, a defesa de *Battisti*, em 03.01.2011, durante o recesso, requereu a imediata expedição de **alvará de soltura**, e, em contrapartida, o governo italiano, no dia seguinte, peticionou no sentido da manutenção da prisão e que a decisão fosse tomada pelo Pleno e não monocraticamente.

Dessa maneira, o STF teve de julgar a **Rcl 11.243** interposta pela República italiana em razão de decisão do Chefe do Executivo brasileiro que, ao negar o pedido de extradição, estaria, conforme sustentado, supostamente violando a decisão proferida na *Ext 1.085*.

Em 09.06.2011, por 6 x 3, a Corte entendeu tratar-se de **ato de governo**, marcado pela **ampla discricionariedade** (ao decidir pela não extradição nos termos do tratado) e, assim, verdadeiro **ato de soberania nacional**:

“(…). No campo da **soberania**, relativamente à extradição, é assente que o ato de entrega do extraditando é exclusivo, da **competência indeclinável do presidente da República**, conforme consagrado na Constituição, nas leis, nos tratados e na própria decisão do Egrégio STF na *Ext 1.085*. **O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao STF**, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da República italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art. 92 da Carta das Nações Unidas de 1945” (**Rcl 11.243**, Rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. 08.06.2011, Plenário, *DJE* de 05.10.2011).

■ 16.6.2.1.7. *Expulsão*

O **art. 65** da Lei n. 6.815/80 entende passível de **expulsão** o **estrangeiro** que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.²⁷

Compete exclusivamente ao Presidente da República, por **decreto**, resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação, ficando, contudo, o ato expulsório sujeito ao controle de constitucionalidade e legalidade pelo Judiciário, por meio de *habeas corpus*.

Diferentemente da **extradição passiva**, que se funda na prática de delito **fora do território nacional**, a hipótese de **expulsão** dar-se-á quando o delito ou infração (ato que atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne o estrangeiro nocivo à conveniência e aos interesses nacionais, além das hipóteses do parágrafo único do art. 65 da Lei n. 6.815/80) for cometido **dentro do território nacional**, caracterizando-se como verdadeiro instrumento coativo de retirada do estrangeiro do território pátrio, nas hipóteses descritas na lei (art. 22, XV, da Constituição Federal). A expulsão, portanto, prescinde (dispensa) de provocação da autoridade estrangeira, ao contrário do que ocorre com a extradição.

Por fim, a lei, em seu **art. 75**, veda a expulsão do estrangeiro nas seguintes hipóteses:

- se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira;
- quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos;
- quando o estrangeiro tiver filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente, não constituindo impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar.

Em relação à existência de **cônjuge**, temos sugerido uma interpretação mais ampla, abrangendo, naturalmente, a preservação das entidades familiares

fundadas também em **uniões estáveis hétero** ou **homoafetivas** (**matéria pendente** de análise específica pelo STF).

Quanto à expressa literalidade do art. 75, § 1.º, da Lei n. 6.815/80, no sentido de não obstar a expulsão se o **filho** for concebido ou tiver nascido **após** a prática do delito ensejador da medida de expulsão, de modo geral o **STF** (muito embora se reconheça interpretação mais flexível no **STJ** à luz dos arts. 227 e 229 da CF/88, do *Estatuto da Criança e do Adolescente* e do Decreto n. 99.710/90, que promulga a *Convenção sobre os Direitos da Criança*)²⁸ vem adotando a **posição mais restritiva**, expressa no texto legal.²⁹

Vislumbra-se, **contudo**, em nosso entender **acertadamente**, a possibilidade de modificação da jurisprudência da Corte, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral no **RE 608.898 (matéria pendente)**.

Isso porque, de acordo com o precedente citado do STJ, segundo o Min. Teori Zavascki (que assumiu como Ministro do STF em 29.11.2012), “a proibição de expulsão de estrangeiro que tenha filho brasileiro objetiva resguardar os **interesses da criança**, não apenas no que se refere à assistência material, mas à sua **proteção** em sentido **integral**, inclusive com a garantia dos **direitos à identidade**, à **convivência familiar**, à **assistência pelos pais**”.

Dessa forma, para nós, seriam causas obstaculizadoras da expulsão, também, a existência de nascituro ou mesmo o nascimento de filho após a prática do delito. Temos de aguardar a análise do STF em relação a esse tema tão importante que envolve o reconhecimento ou não do **vínculo de afetividade** como causa autônoma e impeditiva do ato de expulsão.³⁰

■ 16.6.2.1.8. **Deportação**

Assim como os outros dois institutos estudados, é outro modo de devolução do estrangeiro ao exterior. A diferença baseia-se no fato de não estar a deportação ligada à prática de delito, mas sim aos casos de **entrada** ou **estada irregular de estrangeiro**, se este não se retirar **voluntariamente** do território nacional no prazo fixado, consubstanciando verdadeira **saída compulsória** do

estrangeiro, para o país de sua nacionalidade ou de procedência, ou para outro que consinta em recebê-lo.

Como se sabe, o **art. 5.º, XV**, da CF/88 estabelece ser livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, **nos termos da lei**, nele **entrar, permanecer** ou dele sair com seus bens. Assim, a **permanência irregular** ou **clandestina** justifica a deportação.

De acordo com os arts. 62 e 63 da Lei n. 6.815/80, não se procederá à deportação se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira, mas, não sendo ela exequível ou quando existirem indícios sérios de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á à sua expulsão.

Finalmente, cabe observar que, a teor do art. 98 do Decreto n. 86.715/81, a deportação incumbe ao **Departamento de Polícia Federal**, que, ao promovê-la, lavrará o respectivo termo.

Eventual *habeas corpus* a ser impetrado contra esse ato será de competência da **Justiça Federal de primeira instância**, na dicção do **art. 109, VII**, da CF/88, e não do STF, já que não estarão configuradas as hipóteses do art. 102, I, “d” e “i”, **salvo** se se caracterizar **extradição indireta**. Isso porque, de acordo com o art. 63 da Lei n. 6.815/80, como visto, **não se procederá à deportação se implicar em extradição inadmitida pela lei brasileira**.³¹

■ 16.6.2.1.9. **Banimento: existe expulsão ou banimento de brasileiros?**

Não. Isso porque o envio compulsório de brasileiros ao estrangeiro, que caracterizaria a **pena de banimento**, é inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 5.º, XLVII, “d”, da Constituição Federal).

■ 16.6.2.1.10. **Asilo político e refúgio (direito de permanecer no Brasil)**

Se por um lado vimos os mecanismos de entrega, agora a análise se dá no que respeita ao **direito de permanecer no Brasil**, seja pelo visto, seja em razão das regras decorrentes de tratados, seja pelo **asilo político** ou **refúgio**.

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio de concessão de **asilo político**, regulado em diversos tratados dos quais o Brasil é signatário (art. 4.º, X).

Segundo Rezek, **asilo político** “... é o acolhimento, pelo Estado, de estrangeiro perseguido alhures — geralmente, mas não necessariamente, em seu próprio país patrial —, por causa de dissidência política, de delitos de opinião, ou por crimes que, relacionados com a segurança do Estado, não configuram quebra do direito penal comum”.³²

O art. XIV — I da *Declaração Universal dos Direitos Humanos* (1948) estabelece que “toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar **asilo** em outros países”. No entanto, esclarece, em seu item II, que mencionado direito não poderá ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos ou princípios das Nações Unidas. Nessa mesma linha, o art. 7.º do *Pacto de San José da Costa Rica* prescreve que o direito de receber asilo em território estrangeiro se restringe às hipóteses de **perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com os delitos políticos**.

O **asilo político** é gênero do qual são espécies o *asilo territorial* e o *asilo diplomático*:

■ **asilo territorial**: concedido ao estrangeiro no âmbito espacial da soberania estatal;

■ **asilo diplomático**: concedido ao estrangeiro pela autoridade diplomática brasileira no exterior, ficando protegido, por exemplo, na Embaixada, no Consulado, em navio, aeronave, acampamento militar etc.

O **asilo político** não se confunde com o **refúgio**. Enquanto o **asilo político** relaciona-se ao **indivíduo perseguido**, o **refúgio** decorre de um abalo maior das estruturas de determinado país e que, por esse motivo, possa gerar vítimas em potencial.

O **refúgio** é solicitado ao *Comitê Nacional para os Refugiados*, que funciona no Ministério da Justiça e está regulamentado na Lei n. 9.474/97, que dispõe, em seu art. 1.º, ser reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

- devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

- não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;

- devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

■ **16.6.2.2. Cargos privativos de brasileiros natos**

O art. 12, § 3.º, da CF/88 estabelece que alguns cargos serão ocupados somente por brasileiros natos, fazendo expressa diferenciação em relação aos brasileiros naturalizados, fato esse perfeitamente possível, já que introduzido pelo poder constituinte originário. Assim, são privativos de brasileiro nato os cargos:

- de Presidente e Vice-Presidente da República;
- de Presidente da Câmara dos Deputados;
- de Presidente do Senado Federal;
- de Ministro do STF;
- da carreira diplomática;
- de oficial das Forças Armadas;
- de Ministro de Estado da Defesa. [33](#)

■ **16.6.2.3. Atividade nociva ao interesse nacional**

De acordo com o art. 12, § 4.º, I, somente o **brasileiro naturalizado** poderá perder a nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

■ 16.6.2.4. Conselho da República

Como já vimos, dentre os componentes do Conselho da República (art. 89), órgão superior de consulta do Presidente da República, além do Vice-Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado Federal, dos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, dos líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, do Ministro da Justiça, dele participam:

■ **seis cidadãos brasileiros natos**, com mais de **35 anos de idade**, sendo **2** nomeados pelo Presidente da República, **2** eleitos pelo Senado Federal e **2** eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução.

■ 16.6.2.5. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

Pela redação original, antes da reforma trazida pela **EC n. 36, de 28 de maio de 2002**, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens era, **por regra geral**, privativa de pessoas físicas (brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos), vedando-se a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa. Excepcionalmente, contudo, **sem qualquer direito a voto** e limitada a **30% do capital social**, permitia-se a participação de *partido político* e de *sociedades cujo capital pertencesse exclusiva e nominalmente a brasileiros*.

Com a nova redação conferida ao art. 222, *caput*, da CF/88, **pela EC n. 36/2002**, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa:

- de **brasileiros natos** ou;
- de **brasileiros naturalizados há mais de 10 anos** ou;
- de **pessoas jurídicas** constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

Percebe-se, desta feita, mais uma das hipóteses em que há expressa distinção constitucional entre brasileiro nato e naturalizado.

Remetemos o nosso querido leitor para o *item 19.7.3*, no qual tratamos do importante tema da **comunicação social**, tendo em vista as novidades trazidas pela **EC n. 36/2002**.

■ 16.7. PERDA DA NACIONALIDADE

■ 16.7.1. Hipóteses de perda da nacionalidade

As hipóteses de perda da nacionalidade estão **taxativamente** previstas na CF/88, nos incisos I e II do § 4.º do art. 12. Assim, os pressupostos para declaração da perda da nacionalidade são:

- cancelamento da **naturalização** por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional (art. 12, § 4.º, I);
- aquisição de outra nacionalidade (art. 12, § 4.º, II).

■ 16.7.1.1. *Cancelamento da naturalização*

O pressuposto para o cancelamento da naturalização está previsto na CF/88 (**atividade nociva ao interesse nacional**), bem como o seu instrumento (cancelamento através de **sentença judicial transitada em julgado**). O procedimento, por sua vez, está disciplinado nos arts. 24 a 34 da Lei n. 818, de 18.09.1949 (instaurado o inquérito para apurar se houve prática de atividade nociva ao interesse nacional, após tomar vistas, o órgão do Ministério Público Federal poderá oferecer denúncia, instaurando o processo judicial de cancelamento. A decisão que concluir pelo cancelamento da naturalização terá efeitos *ex nunc*, ou seja, o indivíduo só perde a naturalização a partir da sentença).

Devemos aclarar que o processo de **cancelamento da naturalização** atingirá

somente o brasileiro **naturalizado**, e não o nato, que, como veremos, só poderá perder a nacionalidade na hipótese de aquisição de outra nacionalidade (salvo os permissivos constitucionais).

A regra contida no art. 12, § 4.º, I, foi discutida pelo STF em interessante caso.

Tratava-se do **RMS 27.840**, em que austríaco naturalizado brasileiro (portanto, *brasileiro naturalizado*, e não *nato*) buscava rever **ato administrativo** editado pelo *Ministro da Justiça*, pelo qual se cancelou a referida naturalização, cujo pedido havia sido instruído com documentos falsos, já que se apurou que ele tinha condenação criminal anterior à naturalização.

O Min. Lewandowski negou provimento ao recurso, sustentando que o cancelamento administrativo se deu diante da possibilidade que a Administração tem de rever os seus atos quando eivados de vício insanável (S. 473/STF) e, ainda, nos termos do art. 112, §§ 2.º e 3.º, [34](#) da Lei n. 6.815/80, na medida em que a discussão não analisava o crime, mas a falsidade da documentação apresentada, qual seja, a **fraude**.

Contudo, o STF, por maioria, decidiu que, de acordo com a literalidade do art. 12, § 4.º, I, a perda da nacionalidade, mesmo diante das circunstâncias do caso, somente poderá ser verificada por **sentença judicial transitada em julgado**, e não por ato administrativo.

Isso porque, para a Min. Cármen Lúcia, Relatora, seguida pela maioria dos Ministros, muito embora os §§ 2.º e 3.º do art. 112 da Lei n. 6.815/80 tivessem sido recepcionados pela CF/88, o **Decreto Legislativo n. 274/2007**, que aprova o texto da *Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia*, celebrada em 30 de agosto de 1961, **revogou-os**.

Assim, na medida em que a referida Convenção prevê a perda da nacionalidade somente por decisão de “Tribunal” ou “órgão independente”, e como no Brasil não existem os ditos “órgãos independentes” na estrutura administrativa, a única forma de perda da nacionalidade seria por sentença judicial transitada em julgado.

■ 16.7.1.2. Aquisição de outra nacionalidade

Também perderá a nacionalidade (e aqui a terminologia utilizada é nacionalidade, e não naturalização) o brasileiro nato ou naturalizado que, voluntariamente, **adquirir outra nacionalidade**.

Ao contrário do cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, a perda da nacionalidade em decorrência da aquisição de outra dar-se-á após procedimento administrativo, em que seja assegurada a ampla defesa, por **decreto do Presidente da República** (art. 23 da Lei n. 818/49).

A ECR n. 3/94, alterando a redação do art. 12, § 4.º, II, estabeleceu duas hipóteses em que a aquisição de outra nacionalidade (dupla nacionalidade) não implicará a perda da brasileira. São elas:

■ **reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira:**

trata-se do reconhecimento da nacionalidade originária, ou seja, aquela adquirida com o nascimento (primária). Ex.: o indivíduo que nasceu no território brasileiro, filho de italianos que estavam em férias no Brasil (obs.: não se encontravam a serviço da Itália), será brasileiro nato (art. 12, I, “a” — *ius solis*) e poderá adquirir a nacionalidade italiana (*ius sanguinis*) sem perder a brasileira;

■ **imposição de naturalização pela norma estrangeira:**

o brasileiro residente em Estado estrangeiro e, como condição para sua permanência naquele país (por motivo de trabalho, exercício profissional), ou para o exercício de direitos civis (herança, por exemplo), tiver, por imposição da norma estrangeira, de se naturalizar, não perderá a nacionalidade brasileira.

■ 16.8. REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA PERDIDA

Cancelada a naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional (art. 12, § 4.º, I), ou perdida a nacionalidade (primária ou secundária) em decorrência da aquisição de outra nacionalidade fora dos permissivos constitucionais (art. 12, § 4.º, II), seria possível readquiri-

las?

■ **cancelamento da naturalização:** não poderá readquiri-la, a não ser mediante **ação rescisória**, nunca por meio de um novo processo de naturalização, sob pena de contrariedade ao texto constitucional;

■ **aquisição de outra nacionalidade:** o art. 36 da Lei n. 818/49 prevê a possibilidade de reaquisição por decreto presidencial, se o ex-brasileiro estiver domiciliado no Brasil. Entendemos, contudo, que tal dispositivo só terá validade se a reaquisição não contrariar os dispositivos constitucionais e, ainda, se existirem elementos que atribuam nacionalidade ao interessado. [35](#)

■ 16.9. QUESTÕES

1. (OAB/100.º) São poucas as limitações aos brasileiros naturalizados. Apenas algumas enunciadas pela Constituição, verificáveis nas hipóteses resumidas assim: 1) são privativos de brasileiros natos os cargos de: Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do Supremo Tribunal Federal; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas (art. 12, § 3.º); [36](#) 2) também é privativa de cidadão brasileiro nato a função de Membro do Conselho da República (art. 89, VII); 3) o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou em caso de crime comum, ainda que praticado antes da naturalização (art. 5.º, LI); 4) o brasileiro naturalizado há menos de dez anos não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222). Use o Código:

- a) desde que estejam corretas as asserções 1-2-3 e 4;
- b) desde que estejam corretas apenas as asserções 1-2 e 4;
- c) desde que estejam corretas apenas as asserções 2-3 e 4;
- d) desde que estejam corretas apenas as asserções 1-2 e 3.

2. (OAB/114.º) Ao estrangeiro, naturalizado brasileiro, é vedado:

- a) ser contratado como professor de universidade pública;
- b) ser presidente do Senado Federal;

- c) prestar concurso público para ingresso no serviço público federal;
- d) filiar-se a partido político.

3. (Magistratura/174.º) Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos:

- a) brasileiros natos;
- b) brasileiros naturalizados;
- c) estrangeiros residentes;
- d) estrangeiros não residentes.

4. (Técnico — MPU — 2007 — FCC) Também são considerados brasileiros natos os nascidos

- a) no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que um deles não esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- b) na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
- c) no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, independente de optarem pela nacionalidade brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil.
- d) no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos não estejam a serviço da República Federativa do Brasil.
- e) no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem pela nacionalidade brasileira até a maioridade.

5. (Adv. Petrobras/CESGRANRIO-2008) Maria é brasileira, funcionária da Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras, e casada com João, também brasileiro. Foi enviada grávida à Itália, juntamente com sua equipe de trabalho, para tratar de assuntos profissionais do interesse da Petrobras. Ao chegar a Roma, Maria teve complicações na gravidez e deu à luz prematuramente a seu filho Mário, que sobreviveu. De acordo com as disposições constitucionais relativas a direitos da nacionalidade, esse filho de João e Maria será:

- a) apátrida.
- b) estrangeiro.
- c) brasileiro nato.

- d) brasileiro naturalizado.
- e) italiano, podendo optar pela nacionalidade brasileira após a maioridade.

6. (Magistratura-RR/FCC — 2008) Nascido em dezembro de 2007, na França, filho de pai brasileiro e mãe argelina, João é registrado em repartição consular brasileira sediada naquele país. Nessa hipótese, nos termos da Constituição da República, João:

- a) é considerado brasileiro nato.
- b) será considerado brasileiro nato se vier a residir no Brasil e optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
- c) será considerado brasileiro naturalizado, desde que venha a residir por quinze anos ininterruptos no Brasil e não sofra condenação penal.
- d) será considerado brasileiro naturalizado se, na forma da lei, vier a adquirir nacionalidade brasileira.
- e) não será considerado brasileiro.

7. (DP/SC-ACAFE — 2008) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, pode ser extraditado o brasileiro naturalizado, em caso de crime comum, praticado anteriormente à naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, na forma da lei. Portanto, a afirmação acima está:

- a) incorreta, porque o brasileiro nato também pode ser extraditado.
- b) totalmente incompatível com o que dispõe a Constituição no capítulo dos Direitos e Deveres individuais e coletivos.
- c) incorreta, porque a prática do crime comum não autoriza a extradição.
- d) totalmente compatível com o que dispõe a Constituição no capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.

8. (Magistratura/TJ RS — 2009) Pablo nasceu em Buenos Aires. Seu pai é o embaixador brasileiro na Argentina e sua mãe é de nacionalidade argentina. Nos termos da Constituição Federal de 1988 e alterações em vigor, é correto afirmar que Pablo:

- a) poderá naturalizar-se brasileiro após residir no Brasil por mais de quinze anos ininterruptos e não tiver condenação penal.
- b) poderá naturalizar-se brasileiro após a maioridade se residir no Brasil por um ano e

desde que requeira a nacionalidade brasileira.

- c) será considerado brasileiro nato desde que venha residir no Brasil até os vinte e um anos e opte, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- d) será considerado brasileiro nato desde que venha residir no Brasil a qualquer tempo e opte pela nacionalidade brasileira.
- e) é brasileiro nato, independentemente de quaisquer condições.

9. (MP/MA — 2009) Em relação à extradição a Constituição Federal:

- a) admite sempre em se tratando de naturalizado;
- b) permite caso seja provada a participação de brasileiro nato e de naturalizado em crime de tráfico de ilícito de entorpecentes;
- c) permite se comprovado o envolvimento de brasileiro nato ou naturalizado em crime de tráfico ilícito de entorpecente, mas desde que o delito tenha característica internacional, o que autorizará julgamento por Tribunal Internacional;
- d) o brasileiro nato não é passível de extradição;
- e) o naturalizado poderá ser extraditado nas mesmas hipóteses previstas na Constituição para o brasileiro nato, mas desde que o fato seja posterior à naturalização. Se anterior poderá ser expulso.

10. (OAB 138 — UnB/CESPE — 2009) No que concerne à perda e à reaquisição da nacionalidade brasileira, assinale a opção correta:

- a) Eventual pedido de reaquisição de nacionalidade feito por brasileiro naturalizado será processado no Ministério das Relações Exteriores.
- b) A reaquisição de nacionalidade brasileira é conferida por lei de iniciativa do presidente da República.
- c) Em nenhuma hipótese, brasileiro nato perde a nacionalidade brasileira.
- d) Brasileiro naturalizado que, em virtude de atividade nociva ao Estado, tiver sua naturalização cancelada por sentença judicial só poderá readquiri-la mediante ação rescisória.

11. (Defensoria Pública da União — CESPE/UnB — 2010) (...) julgue os próximos itens:

- l) Considere que Melchior, devido a fundado temor de perseguição por motivo de raça, se encontre fora de seu país de nacionalidade e que, tendo ingressado no Brasil, se tenha dirigido à Defensoria Pública e indagado acerca da possibilidade de permanência no

país, em condição de asilo. Nesse caso, é correto que o defensor público recomende a Melchior que requeira refúgio, com base na lei que normatiza o assunto.

- II) Suponha que Raimundo, brasileiro nato, tenha saído do Brasil para morar nos Estados Unidos da América, onde reside há mais de 30 anos, e que, nesse país, tenha obtido a nacionalidade americana como condição para permanecer no território americano. Nessa situação, caso deseje retornar ao Brasil para visitar parentes, Raimundo necessitará de visto, pois, ao obter a nacionalidade americana, perdeu a nacionalidade brasileira.

12. (Oficial da Defensoria Pública do Estado de SP/FCC/2010) O filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no Estado do Ceará em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro (pousada), tem nacionalidade, nos termos da Constituição Federal Brasileira,

- a) alemã.
- b) brasileira.
- c) alemã, considerado naturalizado brasileiro.
- d) brasileira, considerado naturalizado.
- e) brasileira, considerado naturalizado alemão.

13. (Técnico Judiciário — TRE/CE — Área Administrativa — FCC/2012) Péricles, português residente há mais de um ano ininterrupto no Brasil e com idoneidade moral. Pompeu, grego naturalizado brasileiro. Cipriano, inglês residente no Brasil há quinze anos ininterruptos e sem condenação criminal. Alexandre, nascido no Brasil e filho de pais franceses a serviço da França. Tibério, nascido na Bélgica e filho de pai brasileiro a serviço da República Federativa do Brasil, foram cogitados para ocupar cargo de Ministro de Estado da Defesa do Brasil. Nesse caso, segundo a Constituição Federal, o cargo só poderá ser ocupado por

- a) Tibério.
- b) Pompeu.
- c) Cipriano.
- d) Péricles.
- e) Alexandre.

14. (Analista Judiciário/STM — Área Judiciária — CESPE/UnB/2011) O filho de um embaixador do Brasil em Paris, nascido na França, cuja mãe seja alemã, será

considerado brasileiro nato.

15. (Técnico de Controle Externo — TCE/SE — FCC/2011) Paulo, brasileiro nato, é jogador de futebol e atua em um determinado clube da Itália. Como condição de permanência no País onde atua e manutenção do exercício de sua atividade profissional, a Itália impõe a Paulo a sua naturalização. Nesse caso, Paulo:

- a) não terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.
- b) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira até o momento em que ele regressar ao Brasil e optar novamente pela nacionalidade brasileira.
- c) perderá automaticamente a nacionalidade brasileira, mas poderá solicitar a sua reanquirição ao Ministro da Justiça, quando retornar ao Brasil.
- d) terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.
- e) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira enquanto não cancelar a naturalização italiana.

16. (Defensor Público/AM — Instituto Cidades/2011) Márcio Spaghet, italiano residente no Brasil há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem condenação criminal, requereu a nacionalidade brasileira. Nesse caso:

- a) terá seu *status* de brasileiro naturalizado reconhecido e poderá ser Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- b) não terá o seu *status* de brasileiro naturalizado reconhecido em função da inexistência de reciprocidade por parte do governo italiano.
- c) terá seu *status* de brasileiro naturalizado reconhecido e poderá seguir carreira diplomática e, assim, tornar-se embaixador do Brasil na Itália.
- d) não terá o seu *status* de brasileiro naturalizado reconhecido, pois, não obstante a existência de tratado de reciprocidade, no caso dos estrangeiros, o prazo de residência mínima é de 20 (vinte) anos ininterruptos.
- e) terá seu *status* de brasileiro naturalizado reconhecido e poderá ser eleito Senador da República.

17. (Analista Judiciário — TJ/ES — Área Administrativa — CESPE/UnB/2011) A respeito dos princípios e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir:

O brasileiro nato não poderá ser extraditado para outro país em nenhuma hipótese.

18. (Magistratura/RO — PUC-PR/2011) Em relação às regras constitucionais sobre nacionalidade, estão CORRETAS:

- I. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
 - II. São considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
 - III. São considerados brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 - IV. São considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- a) Todas as afirmativas.
 - b) Somente as afirmativas I, II e III.
 - c) Somente as afirmativas II, III e IV.
 - d) Somente as afirmativas I, III e IV.
 - e) Somente as afirmativas II e IV.

19. (Perito Papiloscópico — PC/ES — CESPE/UnB/2011) No que se refere aos direitos sociais, julgue o item seguinte:

Um cargo de tenente do Exército apenas poderá ser exercido por brasileiro nato.

20. (OAB — Exame de Ordem Unificado.2 — out./2011 — FGV/2011) No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta:

- a) O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade.
- b) O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha a nascer no Brasil.
- c) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização.
- d) O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

21. (Analista Judiciário/CNJ — CESPE/UnB/2013 — Área Judiciária) Julgue o item seguinte, referente à teoria constitucional:

Os estrangeiros somente não gozarão dos mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando a própria Constituição autorizar a distinção, tendo-se presente o princípio de que a lei não deve distinguir entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis.

22. (Analista Judiciário — TRE/RJ — CESPE/UnB/2012) Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição Federal de 1988 (CF):

Com a EC n. 36/2002, a situação jurídica de brasileiros natos e naturalizados, no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, foi igualada.

23. (Analista Ministerial — Área Processual — MP/PI — CESPE/UnB/2012) A respeito de direitos e garantias fundamentais e nacionalidade, julgue o item seguinte.

O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade.

24. (Analista Judiciário — TRF5 — Execução de Mandados — FCC/2012) Uma brasileira naturalizada, casada com um italiano e residente no país de origem de seu marido, dá à luz filhas gêmeas e pretende, dentro de poucos anos, voltar em caráter definitivo para o Brasil com a família. De acordo com a Constituição da República, as crianças:

- a) são consideradas estrangeiras enquanto residirem fora do país, podendo ser brasileiras naturalizadas, após fixarem residência no Brasil, desde que optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- b) serão consideradas brasileiras natas desde que sejam registradas em repartição brasileira competente ou, após sua mudança para o Brasil, optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- c) são consideradas brasileiras naturalizadas, assim como a mãe, estando, contudo, sujeitas à perda da nacionalidade brasileira, na hipótese de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei do país em que residiam à época do nascimento.
- d) poderão requerer a nacionalidade brasileira desde que residam no Brasil por mais de trinta anos ininterruptos e sem condenação penal, caso em que serão consideradas brasileiras naturalizadas.
- e) poderão, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira, exigidas apenas residência

por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral, pelo fato de serem filhas de brasileira naturalizada.

25. (Técnico — MPU — Tecnologia da Informação e Comunicação — CESPE/UnB/2013) Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir:

Considere que Gabriel, brasileiro nato, ao retornar para o Brasil após ter residido alguns anos nos Estados Unidos da América (EUA), tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido formal dos EUA.

26. (Assessor Técnico Legislativo — AL/PB — FCC/2013) Marta, filha de mãe e pai argentinos, nasceu no Brasil quando os mesmos passavam férias na cidade do Rio de Janeiro. Glaide, filha de mãe brasileira e pai americano, nasceu em Orlando, quando a sua mãe, a serviço da República Federativa do Brasil apresentava palestra sobre Direitos Humanos. Hernandez, filho de pai brasileiro e mãe uruguaia, nasceu em Montevideu quando seu pai, a serviço da República Federativa do Brasil, laborava nos portos do referido local. Nestes casos, segundo a Constituição Federal brasileira:

- a) apenas Glaide e Hernandez são brasileiros natos.
- b) apenas Marta e Glaide são brasileiras natas.
- c) Marta, Glaide e Hernandez são brasileiros natos.
- d) apenas Marta e Hernandez são brasileiros natos.
- e) apenas Glaide é brasileira nata.

■ GABARITO ■

1. “b”. A hipótese 3 está incorreta, pois a extradição em caso de crime comum só se dará se praticado antes da naturalização. “*Ainda que*” deixa a entender que poderia ser hipótese de extradição se o crime fosse praticado também depois da naturalização, o que é vedado constitucionalmente.

2. “b”. Cf. art. 12, § 3.º, III. Observar que a hipótese formulada trata de brasileiro naturalizado, e não de estrangeiro (cf., ainda, arts. 14, § 2.º; 37, I; e 207, da CF).

3. “b”. Art. 12, § 1.º.
4. “b”. Art. 12, I, “a”, da CF/88.
5. “c”. Art. 12, I, “b”, da CF/88 — cf. parte teórica para a expressão “a serviço do Brasil”.
6. “a”. Art. 12, I, “c”, da CF/88 — essa questão exigia o conhecimento da EC n. 54/2007.
7. “d”. Art. 5.º, LI, da CF/88.
8. “e”. Art. 12, I, “b”, da CF/88.
9. “d”.
10. “d”. Art. 12, § 4.º, da CF/88.
11. I) “certo”. Conforme art. 1.º, I, da Lei n. 9.474/97 (<i>vide</i> parte teórica, <i>item 16.6.2.1</i> , caso <i>Cesare Battisti</i>). Vejam a importância de estarmos atentos aos temas do momento! II) “errado”. Por força do art. 12, § 4.º, II, “a”, ele ainda continua brasileiro nato.
12. “b”. Aliás, trata-se de brasileiro nato, nos termos do art. 12, I, “a”, já que os pais, estrangeiros, não estavam a serviço de seu país, tendo vindo para o Brasil para morar e tocar a pousada.
13. “a”. Já que, nos termos do art. 12, I e II, é o único brasileiro nato (art. 12, § 3.º, VII).
14. “certo”. Nos termos do art. 12, I, “b”.
15. “a”. De acordo com o art. 12, § 4.º, II, “b”.
16. “e”. Cf., art. 12, II, “b”, c/c o art. 12, § 3.º, III (exigência de ser brasileiro nato apenas para ocupar a Presidência do Senado Federal).
17. “certo”. De acordo com o art. 5.º, LI.
18. “a”.
19. “certo”. O meu ilustre leitor teria de lembrar que tenente do Exército é oficial das Forças Armadas e, assim, nos termos do art. 12, § 3.º, VI, tem de ser brasileiro nato. Em relação à hierarquia nas Forças Armadas, cf. <i>item 11.8.6.2.3</i> .

20. “b”. Nos termos do art. 12, I, “a”.
21. “certo”, nos termos do art. 5.º, <i>caput</i> , da CF/88.
22. “errado”, nos termos do art. 222, <i>caput</i> , da CF/88.
23. “certo”. Confira o art. 5.º, LI, e o art. 12, § 4.º, II.
24. “b”. Art. 12, I, “c”. Importante destacar que o fato de ser a mãe brasileira <i>naturalizada</i> não impede que as filhas sejam consideradas pelo Estado como brasileiras <i>natas</i> . Isso porque o art. 12, I, “c”, exige que o pai ou a mãe sejam brasileiros e não fala em nato ou naturalizado. Assim, diante do princípio da isonomia e da regra contida no art. 12, § 2.º, que impede a discriminação, não pode o intérprete estabelecer qualquer distinção.
25. “errado”. Art. 5.º, LI. No caso da extradição passiva, o brasileiro nato jamais será extraditado.
26. “c”. Marta, art. 12, I, “a”; Glaide, art. 12, I, “b”; Hernandes, art. 12, I, “b”.

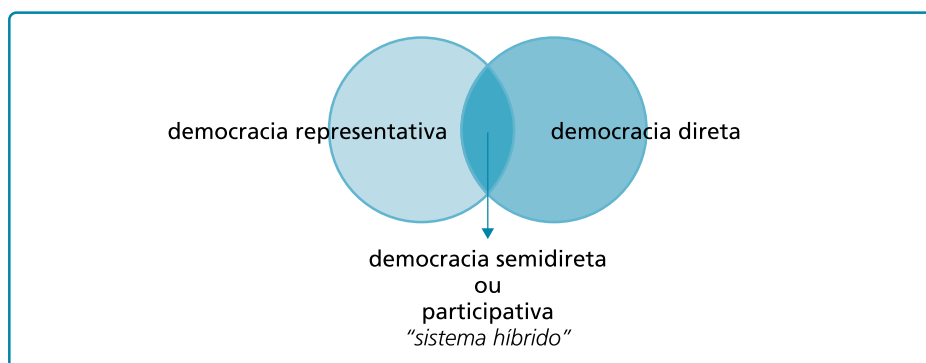
DIREITOS POLÍTICOS

■ 17.1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

■ 17.1.1. Democracia semidireta ou participativa

Os **direitos políticos** nada mais são que instrumentos por meio dos quais a CF garante o exercício da **soberania popular**, atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa pública, seja direta, seja indiretamente. [1](#)

De modo geral podemos classificar os regimes democráticos em três espécies: **a) democracia direta**, em que o povo exerce por si o poder, sem intermediários, sem representantes; **b) democracia representativa**, na qual o povo, soberano, elege representantes, outorgando-lhes poderes, para que, em nome deles e para o povo, governem o país; e **c) democracia semidireta** ou **participativa**, um “sistema híbrido”, uma democracia representativa, com peculiaridades e atributos da democracia direta, a qual, conforme observação de Mônica de Melo, constitui um mecanismo capaz de propiciar, “além da participação direta, concreta do cidadão na democracia representativa, controle popular sobre os atos estatais”. [2](#)



A **democracia participativa** ou **semidireta** assimilada pela CF/88 (arts. 1.º, parágrafo único, e 14) caracteriza-se, portanto, como a base para que se possa, na atualidade, falar em **participação popular no poder por intermédio de um processo**, no caso, o exercício da soberania, que se instrumentaliza por meio do plebiscito, referendo, iniciativa popular, bem como pelo ajuizamento da ação popular.

Passemos, então, a conceituar cada um dos institutos da **democracia direta** (soberania popular). Começamos diferenciando *plebiscito* de *referendo*.

Ao diferenciar os institutos, procuramos apontar os pontos de aproximação (semelhanças) e os pontos de distinção (diferenças). A semelhança entre eles reside no fato de ambos serem formas de consulta ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.

A diferença está no **momento da consulta**: *a)* no plebiscito, a consulta é prévia, sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, por meio do voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido à apreciação. Ou seja, primeiro consulta-se o povo, para depois, só então, a decisão política ser tomada, ficando o governante condicionado ao que for deliberado pelo povo; *b)* por outro lado, no *referendum*, primeiro se tem o ato legislativo ou administrativo, para, só então, submetê-lo à apreciação do povo, que o ratifica (confirma) ou o rejeita (afasta).

O art. 3.º da Lei n. 9.709/98 estabelece que nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3.º do art. 18 da CF, o plebiscito e o referendo são convocados mediante

decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional. Recorde-se, por fim, que a competência para **autorizar** referendo e **convocar** plebiscito, de acordo com o art. 49, XV, da CF/88, é **exclusiva** do **Congresso Nacional**, materializada, como visto, por **decreto legislativo**.

O outro instrumento de participação popular, por intermédio de um processo, de forma direta, no exercício do poder, dá-se por **iniciativa popular**, que consiste, em âmbito federal, na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, cinco Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles (ver art. 61, § 2.º, da CF/88).³

Finalmente, além das já citadas formas de **participação popular**, podemos lembrar a **ação popular** (que foi mais bem estudada junto com os remédios constitucionais — Cap. 14), bem como diversas outras previstas, a título de exemplo, nos arts. 10; 11; 31, § 3.º; 37, § 3.º; 74, § 2.º; 194, parágrafo único, VII; 206, VI; 216, § 1.º etc., todos da CF/88.

■ 17.1.2. Plebiscito *versus* referendo: experiências na história brasileira

Surge então a importante pergunta: há alguma experiência de **plebiscito** ou de **referendo** na **história das eleições no Brasil**?

■ 17.1.2.1. *Referendo para manutenção ou não do regime parlamentarista (1963)*

Em um primeiro momento, lembramos a **EC n. 4, de 02.09.1961**, à Constituição de 1946, que, em seu art. 25, fixou a possibilidade de lei complementar “... dispor sobre a realização de ‘plebiscito’ que decida sobre a manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se a ‘consulta plebiscitária’ nove meses antes do termo do atual período presidencial”.

Determinou-se, então, a realização do denominado “plebiscito” para o ano de 1965, com o objetivo de saber se o sistema de governo parlamentar deveria ser mantido ou se o sistema presidencial seria retomado.

Parece-nos que se tratava, em essência, de **referendo**, uma vez que, depois de já tomado o ato (a instituição do **parlamentarismo** no Brasil), proceder-se-ia à consulta popular para confirmar ou afastar tal decisão.

Essa situação foi reconhecida pela **LC n. 2, de 16.09.1962**, que, antecipando a consulta popular, em seu art. 2.º, estabeleceu que “a Emenda Constitucional n. 4, de 2 de setembro de 1961, será submetida a **referendum** popular no dia 6 de janeiro de 1963”, completando em seus parágrafos: “proclamado pelo Superior Tribunal Eleitoral o resultado, o Congresso organizará, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, o sistema de governo na base da opção decorrente da consulta” (ou seja, a consulta vincula a decisão a ser tomada). Em seguida estabeleceu: “terminado esse prazo, se não estiver promulgada a emenda revisora do parlamentarismo ou instituidora do presidencialismo, continuará em vigor a Emenda Constitucional n. 4, de 2 de setembro de 1961, ou voltará a vigorar em sua plenitude a Constituição Federal de 1946, conforme o resultado da consulta popular”.

Portanto, com todo o respeito a eventual entendimento contrário, a nosso ver, o primeiro **referendo** realizado no Brasil foi o do dia 6 de janeiro de 1963, em que foi decidido o retorno ao sistema presidencial.

■ **17.1.2.2. Plebiscito para a escolha entre a forma (república ou monarquia constitucional) e sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) (1993)**

Posteriormente, tivemos o primeiro **plebiscito** no Brasil, com data inicial prevista para 7 de setembro de 1993, nos termos do art. 2.º do ADCT, antecipada para 21 de abril de 1993 pela EC n. 2/92. O **resultado** todos já conhecem — a manutenção da **república constitucional** e do **sistema presidencialista de governo**.

■ **17.1.2.3. Referendo para a manifestação do eleitorado sobre a manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional (2005)**

Chegamos ao **referendo** sobre o **desarmamento**, de 23 de outubro de 2005.

O art. 35 da Lei n. 10.826/2003 (conhecida como **Estatuto do Desarmamento**) proibiu a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das entidades relacionadas no art. 6.º da Lei.

Tal proibição, contudo, a teor do art. 35, § 1.º, para entrar em vigor **dependia** de aprovação mediante **referendo popular**, com realização prevista para outubro de 2005.

Em caso de aprovação do referendo popular, a proibição do *caput* do art. 35 entraria em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O Estatuto do Desarmamento foi regulamentado pelo **Decreto n. 5.123/2004**, tendo sido o **referendo de âmbito nacional**, de que trata o citado art. 35 da Lei n. 10.826/2003, autorizado, nos termos do art. 49, XV, da Constituição Federal, pelo Congresso Nacional, mediante o **Decreto Legislativo n. 780, de 07.07.2005**.

Algumas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) foram ajuizadas contra o **Estatuto do Desarmamento**, destacando-se as de ns. 3.112, 3.137, 3.198, 3.263, 3.518, 3.535, 3.586, 3.600, 3.788 e 3.814.

Para se ter um exemplo, na ADI 3.535, a ADEPOL atacou dispositivos do Estatuto e a totalidade do citado Decreto Legislativo n. 780/2005.

Conforme noticiado, “a entidade afirma que a legislação questionada repercute diretamente nas atividades relativas à defesa do Estado, pois a proibição da comercialização de armas de fogo e munição ‘privará os cidadãos brasileiros de bem de seu direito líquido e certo à compra, propriedade, posse e guarda dessas armas’. Isso poderá provocar um brutal aumento da criminalidade, da violência e do contrabando, diz a ADEPOL” (*Notícias STF*, 13.07.2005).[4](#)

Cabe alertar, especialmente aos ilustres candidatos que irão prestar provas para a importante carreira de *Delegado de Polícia*, que, em despacho ordinatório de 16.11.2006, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski determinou o **apensamento** de todas as referidas ADIs à de n. 3.112, já que nesta se impugnava a totalidade da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e nas outras também se buscava “... a invalidação jurídico-constitucional do mesmo diploma legislativo, seja em sua totalidade, seja quanto a determinadas prescrições normativas”. Nesse sentido, estávamos diante de **identidade de objeto entre todas as ADIs indicadas**, justificando-se, assim, o apensamento de todas à primeira (ADI 3.112), como indicado.

Em 02.05.2007, o STF, por maioria, julgou procedente, em parte, o pedido formulado nas várias ADIs e declarou a **inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos arts. 14 e 15 e do art. 21 da Lei n. 10.826/2003** (Estatuto do Desarmamento).

A inconstitucionalidade formal alegada foi afastada, entendendo o STF pela inexistência de violação do art. 61, § 1.º, II, “a” e “e”.

No mérito, somente os dispositivos citados foram declarados inconstitucionais, confirmando o STF a constitucionalidade dos demais dispositivos do Estatuto:

■ **parágrafos únicos dos arts. 14 e 15:** *inafiançabilidade do crime de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, salvo quando estiver registrada em nome do agente, e inafiançabilidade do crime de disparo de arma de fogo* — considerou-se não razoável a vedação da fiança, tendo em vista que “... tais delitos não poderiam ser equiparados a terrorismo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou crimes hediondos (CF, art. 5.º, XLIII). Asseverou-se, ademais, cuidar-se, na verdade, de crimes de mera conduta que, embora impliquem redução no nível de segurança coletiva, não podem ser igualados aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade” (*Inf. 465/STF e Notícias STF*, 02.05.2007 — 19h);

■ **art. 21 do Estatuto do Desarmamento:** *estabelece serem insuscetíveis de liberdade provisória os delitos previstos nos arts. 16*

*(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), 17 (comércio ilegal de arma de fogo) e 18 (tráfico internacional de arma de fogo) — entendeu o STF ter havido violação “... aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal (CF, art. 5.º, LVII e LXI). Ressaltou-se, no ponto, que, não obstante a interdição à liberdade provisória tenha sido estabelecida para crimes de suma gravidade, liberando-se a franquia para os demais delitos, a Constituição não permite a prisão *ex lege*, sem motivação, a qual viola, ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5.º, LV)” (Inf. 465/STF e Notícias STF, 02.05.2007 — 19h).*

Superada essa questão a respeito das regras trazidas pelo Estatuto, cabe notar que o **referendo** foi organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da Lei n. 9.709, de 18 de novembro de 1998, para consultar o eleitorado sobre a comercialização de armas de fogo e munição no território nacional, tendo sido realizado em **23 de outubro de 2005**, e consistiu na seguinte questão: “o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”.

Se a maioria simples do eleitorado nacional se manifestasse afirmativamente (“SIM”) à questão proposta, a vedação constante do Estatuto do Desarmamento entraria em vigor na data de publicação do resultado do referendo pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Como todos sabem, após a apuração dos votos do aludido referendo, realizado em 23.10.2005, segundo dados oficiais do TSE, o **“NÃO”** recebeu 59.109.265 votos (63,94%) e o “SIM”, 33.333.045 votos (36,06%). Foram registrados 1.329.207 (1,39%) votos em branco e 1.604.307 (1,68%) votos nulos. Dos 122.042.825 eleitores, compareceram às urnas 95.375.824 (78,15%). A abstenção foi de 26.666.791 (21,85%). Assim, o **comércio de armas de fogo e munição**, nos termos da lei e por força do referendo, continua **permitido** no Brasil.

Concordamos com Jorge Hélio ao afirmar que, “da mesma forma que se dá nas eleições convencionais, nas quais o eleitorado escolhe os chefes do Poder Executivo e os membros do Poder Legislativo, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, o voto será obrigatório no referendo vindouro para os

maiores de 18 e com menos de 70 anos, alfabetizados. Os analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles com idades entre 16 e 17 anos, desde que alistados eleitoralmente, votarão se assim quiserem. Para este grupo de pessoas, o voto é facultativo, como reza o art. 14, § 1.º, da Constituição”.[5](#)

■ **17.1.2.4. Referendo no Estado do Acre para decidir sobre o fuso horário (2010)**

O **Decreto Legislativo n. 900/2009** convocou, com fundamento no art. 49, XV, c/c o parágrafo único do art. 1.º e o art. 14, II, da CF/88, **referendo** a ser realizado no Estado do Acre, que teve a hora legal alterada pela **Lei n. 11.662/2008** para menos 1 hora em relação a Brasília (reduzindo, assim, de 4 para 3 os fusos horários no Brasil), para consultar o eleitorado do Estado sobre a conveniência e a oportunidade da referida alteração.

O eleitorado foi chamado a responder “Sim” ou “Não” à seguinte questão: “Você é a favor da recente alteração do horário legal promovida no seu Estado?”

Com 56,87% dos votos, os eleitores do Acre decidiram pelo retorno do fuso horário antigo, de duas horas de diferença em relação a Brasília. A **Lei n. 12.876/2013**, prestigiando a vontade popular, restabeleceu, formalmente, os 4 fusos horários para o território brasileiro.[6](#)

■ **17.1.2.5. Plebiscitos no Estado do Pará para decidir sobre a formação dos Estados do Carajás e do Tapajós (2011)**

O **Decreto Legislativo n. 136/2011** dispôs sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do **Carajás**, nos termos do inciso XV do art. 49 da Constituição Federal, enquanto, por sua vez, o **Decreto Legislativo n. 137/2011** convocou plebiscito sobre a criação do Estado do **Tapajós**, objetivando o processo de *desmembramento formação* em relação ao atual **Estado do Pará**.

Em ambos os casos, mais de 66% dos votos válidos refletiram a vontade da maioria **contra** a criação dos novos Estados (cf. *itens 7.5.1.2 e 7.5.1.6*).

■ 17.1.3. O resultado do plebiscito ou do referendo pode ser modificado por lei ou emenda à Constituição?

Essa pergunta é interessante! Em outras palavras, proclamado o resultado do plebiscito ou do referendo, poderia o legislador contrariar a manifestação popular editando lei ou emenda à Constituição (EC) em sentido contrário?

Exemplificando: tendo o povo confirmado, pelo voto, ser contra a proibição do porte de armas, poderia o legislador editar uma lei em sentido contrário? Essa lei teria validade?

Ou, ainda, tendo o povo manifestado em plebiscito a preferência pelo *presidencialismo*, poderia uma emenda à Constituição instituir o *parlamentarismo* no Brasil?

Entendemos que tanto a lei como a EC seriam flagrantemente **inconstitucionais**. Isso porque, uma vez manifestada a vontade popular, esta passa a ser vinculante, não podendo ser desrespeitada. No caso, seus dispositivos seriam inconstitucionais por violarem o art. 14, I ou II, c/c o art. 1.º, parágrafo único, qual seja, o **princípio da soberania popular**.

Assim sendo, parece-nos possível concluir que a **democracia direta prevalece sobre a democracia representativa**.

A única maneira de modificar a vontade popular seria mediante uma nova consulta ao povo, a ser convocada ou autorizada por **decreto legislativo** do Congresso Nacional (art. 49, XV).

Cumpre alertar, contudo, que o decreto legislativo dependeria de provocação do legislador, seja por meio de lei (no caso do porte de armas), seja por meio de nova emenda (no caso do sistema de governo). Nessas hipóteses, a lei ou emenda deveria prever a futura convocação pelo Congresso Nacional do novo plebiscito.

■ 17.1.4. Quadro comparativo: plebiscito *versus* referendo

--	--	--	--	--

	CONCEITO	CONGRESSO NACIONAL (Competência Exclusiva)	INSTRUMENTO PARA CONVOCAR PLEBISCITO E AUTORIZAR REFERENDO	PRINCIPAL DIFERENÇA — Momento da Consulta
PLEBISCITO	■ consulta formulada ao povo, efetivando-se em relação àqueles que tenham capacidade eleitoral ativa, para que deliberem sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa	■ art. 49, XV — convoca plebiscito	■ decreto legislativo	■ prévia — o plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido
	■ consulta formulada ao povo, efetivando-se em relação àqueles que tenham			■ posterior — o referendo é convocado com posterioridade

REFERENDO	capacidade eleitoral ativa, para que deliberem sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa	■ art. 49, XV — autoriza referendo	■ decreto legislativo	a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição
------------------	---	--	-----------------------	---

■ 17.1.5. Outros institutos de democracia semidireta ou participativa: *recall* e veto popular

Outros institutos de democracia semidireta poderiam ser mencionados, como o *recall* e o veto popular, não adotados, porém, pelo constituinte de 1988:

■ ***recall***: com a sua origem nos EUA, o *recall* seria um mecanismo de **revogação popular do mandato eletivo**, por exemplo, em razão de não cumprimento de promessas de campanha. José Afonso da Silva denomina “**revocação popular**”, definindo-a como um “instituto de natureza política pelo qual os eleitores, pela via eleitoral, podem revocar mandatos populares”;⁷

■ **veto popular**: instrumento pelo qual o povo poderia vetar projetos de lei, podendo arquivá-los, mesmo contra a vontade do Parlamento. Segundo Agra, “a diferença entre o *veto popular* e o plebiscito é que, *naquele*, o seu uso se restringiria a projetos de leis que estivessem tramitando no Congresso Nacional, manifestando-se a população contra a sua aprovação, e este se refere a qualquer propositura que a população tenha interesse que passe a integrar o ordenamento jurídico, independentemente de sua tramitação no Congresso Nacional”.⁸

■ 17.2. SOBERANIA POPULAR, NACIONALIDADE, CIDADANIA, SUFRÁGIO, VOTO E ESCRUTÍNIO

Vejamos alguns conceitos básicos antes de analisar a teoria dos direitos políticos:

■ **Soberania popular**, de acordo com Uadi Lammêgo Bulos, “... é a qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos de cada membro da sociedade estatal, encarregado de escolher os seus representantes no governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário”.[9](#)

■ **Nacionalidade**, como vimos, é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse Estado e, por consequência, desfrute de direitos e submeta-se a obrigações.

■ **Cidadania** tem por pressuposto a nacionalidade (que é mais ampla que a cidadania), caracterizando-se como a **titularidade** de direitos políticos de votar e ser votado.[10](#) O cidadão, portanto, nada mais é que o nacional que goza de direitos políticos.

■ **Sufrágio** é o direito de votar e ser votado.

■ **Voto** é o ato por meio do qual se exercita o sufrágio, ou seja, o direito de votar e ser votado.

■ **Escrutínio** é o modo, a maneira, a forma pela qual se exercita o voto (público ou secreto).

■ 17.3. DIREITO POLÍTICO POSITIVO (DIREITO DE SUFRÁGIO)

Como núcleo dos direitos políticos tem-se o direito de sufrágio, que se caracteriza tanto pela **capacidade eleitoral ativa** (direito de votar, capacidade de ser eleitor, alistabilidade) como pela **capacidade eleitoral passiva** (direito de ser votado, elegibilidade).

■ 17.3.1. Capacidade eleitoral ativa

O exercício do sufrágio ativo dá-se pelo **voto**, que pressupõe: *a)* alistamento eleitoral na forma da lei (título eleitoral); *b)* nacionalidade brasileira (não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros — art. 14, § 2.º); *c)* idade mínima de 16 anos (art. 14, § 1.º, II, “c”); e *d)* não ser conscrito [11](#) durante o serviço militar obrigatório.

Em relação ao **título de eleitor**, a Lei n. 12.034/2009 introduziu o art. 91-A à Lei n. 9.504/97 estabelecendo que no momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deveria apresentar documento de identificação com fotografia.

A matéria foi questionada no STF por meio da **ADI 4.467** e, às vésperas das eleições de 2010, a Corte, por maioria, entendeu que a necessidade de *dupla identificação* violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Bastaria a apresentação de documento oficial com foto para o exercício da *capacidade eleitoral ativa*, não sendo o título documento de apresentação obrigatória (medida cautelar deferida, **mérito pendente**).

Assim, o alistamento eleitoral e o voto são, de acordo com o art. 14, § 1.º, I e II, “a”, “b” e “c”:

OBRIGATÓRIOS	■ maiores de 18 e menores de 70 anos de idade.
FACULTATIVOS	■ maiores de 16 e menores de 18 anos de idade; ■ analfabetos; ■ maiores de 70 anos de idade.

O voto é direto, secreto, universal, periódico, livre, personalíssimo e com valor igual para todos:

■ **direto**, no sentido de que o cidadão vota diretamente no candidato, sem intermediário. Excepcionalmente, porém, existe uma única hipótese de **eleição indireta** no Brasil, já estudada no capítulo sobre o Poder Executivo (art. 81, § 1.º), qual seja, quando vagarem os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos 2 anos do mandato. Nessa situação excepcional, a eleição para ambos os cargos será feita pelo **Congresso Nacional**, na forma da lei;

■ **secreto**, na medida em que não se dá publicidade da opção do eleitor, mantendo-a em sigilo absoluto;

Nesse contexto, discutiu-se se essa regra explícita do **voto secreto** (prevista no art. 14, *caput*) estender-se-ia, também, para a votação no **Parlamento**.

De maneira interessante, decidiu o STF que as deliberações parlamentares devem pautar-se pelo **princípio da publicidade**, a traduzir dogma do **regime constitucional democrático**. “(...) A cláusula tutelar inscrita no art. 14, *caput*, da Constituição tem por destinatário específico e exclusivo o **eleitor comum**, no exercício das prerrogativas inerentes ao *status activae civitatis*. Essa norma de garantia não se aplica, contudo, ao membro do Poder Legislativo nos procedimentos de votação **parlamentar**, em cujo âmbito prevalece, como regra, o **postulado da deliberação ostensiva ou aberta**. (...) A votação pública e ostensiva nas Casas Legislativas constitui um dos instrumentos mais significativos de **controle** do poder estatal pela sociedade civil” (ADI 1.057-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.04.94, *DJ* de 06.04.2001).

Nesse contexto, destacamos a **EC n. 76/2013**, que **aboliu a votação secreta** nos casos de perda do mandato de Deputado ou Senador (art. 55, § 2.º) e de apreciação do veto (art. 66, § 4.º). Muitas outras situações, contudo, continuam com o voto secreto (cf. *item 9.5*), o que, em nosso entender, viola o dever de prestação de contas dos representantes do povo (**princípio da publicidade**).

■ **universal**, visto que o seu exercício **não está ligado a nenhuma condição discriminatória**, como aquelas de ordem econômica (ter ou não certa renda), intelectual (ser ou não alfabetizado), as concernentes a nome, família, sexo, cor, religião. O voto no Brasil, portanto, **não** é restrito, por

não ser censitário (qualificação econômica) nem capacitário (capacitações especiais, notadamente de natureza intelectual);

■ **periódico**, já que a democracia representativa prevê e exige mandatos por prazo determinado;

■ **livre**, pois o eleitor pode escolher o seu candidato, ou, se preferir, anular o voto ou depositar a cédula em branco na urna. A obrigatoriedade está em comparecer às urnas, depositar a cédula ou, atualmente, votar na urna eletrônica e assinar a folha de votação;

■ **personalíssimo**, pois é vetada a votação por procurador. O voto é exercido pessoalmente pelo cidadão, identificado pelo título eleitoral. Buscando reforçar essa garantia de ser o voto personalíssimo, implantou-se no Brasil um procedimento de **recadastramento biométrico**, sob o fundamento de revisões do eleitorado, com vistas à atualização do cadastro eleitoral (cf. Resolução-TSE n. 23.335/2011);

■ **com valor igual para todos**, decorrente do princípio *one man one vote* — “um homem um voto”, o voto deve ter valor igual para todos, independentemente da cor, sexo, situação econômica, social, intelectual etc. (voto igualitário).

Convém lembrar que o constituinte originário, elevando à categoria de cláusulas pétreas, inadmitiu qualquer proposta de emenda à Constituição tendente a abolir o **voto direto, secreto, universal e periódico** (art. 60, § 4.º, II).

■ 17.3.2. Capacidade eleitoral passiva

A capacidade eleitoral passiva nada mais é que a possibilidade de eleger-se, concorrendo a um mandato eletivo. O direito de ser votado, no entanto, só se torna absoluto se o eventual candidato preencher todas as **condições de elegibilidade** para o cargo ao qual se candidata e, ainda, não incidir em nenhum dos impedimentos constitucionalmente previstos, quais sejam, os **direitos políticos negativos**, que veremos mais adiante.

■ 17.3.2.1. Condições de elegibilidade

O art. 14, § 3.º, estabelece como condições de elegibilidade, na forma da lei:

- nacionalidade brasileira;
- pleno exercício dos direitos políticos;
- alistamento eleitoral;
- domicílio eleitoral na circunscrição;
- filiação partidária;
- idade mínima de acordo com o cargo ao qual se candidata.

No tocante ao requisito da idade, [12](#) essa condição de elegibilidade inicia-se aos 18 anos, terminando aos 35 anos, como se observa pelas regras abaixo transcritas:

- **18 anos** para Vereador;
- **21 anos** para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de paz;
- **30 anos** para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
- **35 anos** para Presidente, Vice-Presidente da República e Senador.

■ 17.4. DIREITOS POLÍTICOS NEGATIVOS

Ao contrário dos direitos políticos positivos, os direitos políticos negativos individualizam-se ao definirem formulações constitucionais restritivas e impeditivas das atividades político-partidárias, privando o cidadão do exercício de seus direitos políticos, bem como impedindo-o de eleger um candidato (capacidade eleitoral ativa) ou de ser eleito (capacidade eleitoral passiva). Começamos pelas **inelegibilidades** para depois analisarmos as situações em que os **direitos políticos ficam suspensos ou são perdidos** (privação dos direitos políticos).

■ 17.4.1. Inelegibilidades

As inelegibilidades são as circunstâncias (constitucionais ou previstas em lei complementar) que impedem o cidadão do exercício total ou parcial da capacidade eleitoral passiva, ou seja, da capacidade de eleger-se. Restringem, portanto, a elegibilidade do cidadão. [13](#)

As inelegibilidades visam proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta (art. 14, § 9.º).

As inelegibilidades estão previstas tanto na **CF** (art. 14, §§ 4.º a 8.º), normas essas que independem de regulamentação infraconstitucional, já que de eficácia plena e aplicabilidade imediata, como em **lei complementar**, que poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. [14](#)

As inelegibilidades podem ser **absolutas** (impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo, taxativamente previstas na CF/88) ou **relativas** (impedimento eleitoral para algum cargo eletivo ou mandato, em função de situações em que se encontre o cidadão candidato, previstas na CF/88 — art. 14, §§ 5.º a 8.º — ou em lei complementar — art. 14, § 9.º).

■ 17.4.1.1. Inelegibilidades absolutas

De acordo com o art. 14, § 4.º, são **absolutamente inelegíveis**, ou seja, não podem exercer a capacidade eleitoral passiva, em relação a qualquer cargo eletivo, o:

■ **inalistável** (quem não pode ser eleitor não pode eleger-se). Os **estrangeiros** [15](#) e, durante o serviço militar obrigatório, os **conscritos** não podem alistar-se como eleitores. Portanto, são considerados **inalistáveis**. Lembramos que o alistamento eleitoral é indiscutível condição de elegibilidade;

■ **analfabeto** (o analfabeto tem direito à alistabilidade e, portanto, direito de votar, mas não pode ser eleito, pois não possui capacidade eleitoral passiva).

■ **17.4.1.2. Inelegibilidades relativas**

O relativamente inelegível, em razão de algumas situações, não pode eleger-se para determinados cargos, podendo, porém, candidatar-se e eleger-se para outros, sob os quais não recaia a inelegibilidade. A inelegibilidade nesses casos dá-se, conforme as regras constitucionais, em decorrência da **função** exercida, de **parentesco**, ou **se o candidato for militar**, bem como em virtude das situações previstas em **lei complementar** (art. 14, § 9.º).

■ **17.4.1.2.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida (por motivos funcionais)**

■ **17.4.1.2.1.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida para um terceiro mandato sucessivo**

O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos **não** poderão ser reeleitos para um **terceiro mandato sucessivo**.

A regra trazida pela EC n. 16/97, alterando a redação do **art. 14, § 5.º**, permite a **reeleição** dos Chefes dos Executivos Federal, Estadual, Distrital e Municipal (Presidente da República, Governadores de Estado, Governador do Distrito Federal e Prefeitos) e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para **um único período subsequente**. Isso nos permite concluir que a inelegibilidade surge somente para um terceiro mandato, **subsequente** e **sucessivo**.

Nada impediria, pela regra atual, que o Ex-Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, reeleito para um segundo mandato (1999-2002), já que

permitida a reeleição para um único período subsequente, após intervalo de uma legislatura (o mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva — 2003-2006), se candidatasse e se reelegesse para um terceiro mandato (2007-2010), porém, como visto, não sucessivo (como todos sabem, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para um novo mandato subsequente).

Por fim, ressaltamos decisão do TSE, em resposta à **Consulta n. 689/2000**, indagando se os vices podem ser candidatos à sucessão do titular reeleito, uma vez que este não pode mais ser candidato a um terceiro mandato sucessivo. A resposta a essa consulta gerou a **Res. n. 20.889/01/TSE** (*DJ* 1, de 14.12.2001, p. 205), pela qual fica estabelecido que o vice, tendo ou não sido reeleito, se sucedeu o titular, poderá candidatar-se à reeleição por um período subsequente. No entanto, para candidatar-se a cargo diverso, deverá observar as regras do art. 1.º, § 2.º, da LC n. 64/90. Do ponto de vista político, para se ter um exemplo, essa decisão beneficiou o então Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, mesmo já tendo, no primeiro mandato, substituído Mário Covas, assumindo como governador interino e, no segundo, como Governador, após a morte de Covas.

Esse entendimento foi mantido pelo STF no julgamento da **RE 366.488**, Rel. Carlos Velloso (04.10.2005), nos seguintes termos: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO TITULAR: REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5.º. I. Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. **Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo.** II. Inteligência do disposto no § 5.º do art. 14 da Constituição Federal. III. RE conhecido e improvido”.

■ 17.4.1.2.1.2. A figura do denominado “prefeito itinerante” ou “prefeito profissional”

O denominado “**prefeito itinerante**” ou “**prefeito profissional**” é aquele que, reeleito em um mesmo Município, na medida em que inelegível para o terceiro mandato consecutivo, transfere o seu domicílio eleitoral para município diverso buscando afastar a inelegibilidade estabelecida no art. 14, § 5.º, da CF/88.

Durante muito tempo, o **TSE** admitiu essa situação, com algumas ressalvas (municípios com territórios limítrofes, a pressupor microrregião eleitoral única ou resultantes de desmembramento, incorporação ou fusão), mas, no julgamento do *Recurso Especial Eleitoral n. 32.507*, em 17.12.2008, a Corte Eleitoral **mudou o seu entendimento**, passando a não mais aceitar essa situação, mesmo se observados os prazos de desincompatibilização, domicílio eleitoral, filiação partidária etc. Vejamos:

‘EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. REGISTRO CANDIDATURA. PREFEITO. CANDIDATO À REELEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO MUNICÍPIO. **FRAUDE CONFIGURADA**. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 5.º DO ART. 14 DA CB. IMPROVIMENTO. 1. Fraude consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de transferir-se domicílio eleitoral de um para outro Município, de modo a ilidir-se a incidência do preceito legal disposto no § 5.º do art. 14 da CB. 2. Evidente **desvio da finalidade do direito à fixação do domicílio eleitoral**. 3. Recurso a que se nega provimento” (**RESPE 32.507**, Rel. Min. Eros Grau, j. 17.12.2008).

O tema chegou a ser discutido pelo STF no julgamento do **RE 637.485**, que, em 1.º.08.2012, manteve o novo entendimento firmado no TSE, não admitindo o terceiro mandato consecutivo, **mesmo na hipótese de municípios distintos**.

O Min. Gilmar Mendes, Relator, “assentou, sob o regime de repercussão geral, que: a) o art. 14, § 5.º, da CF interpretar-se-ia no sentido de que a **proibição da segunda reeleição seria absoluta e tornaria inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já**

cumprira 2 mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso; e b) as decisões do TSE que acarretassem **mudança de jurisprudência** no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento **não se aplicariam imediatamente ao caso concreto** e somente teriam eficácia sobre outras situações em pleito eleitoral posterior”.

Assim, a proibição de reeleições sucessivas ao cargo de Prefeito encontrava fundamento no **princípio republicano**, em respeito à **temporariedade** e à **alternância no exercício do poder**. Contudo, ficou clara a possibilidade de, observada a regra da desincompatibilização 6 meses antes de novo pleito, esse Prefeito, reeleito, sair candidato a **outros** cargos, no caso os de Presidente da República, Governador de Estado, Governador do DF, Deputado federal ou estadual, Vereador, mas não, como se viu, ao de Prefeito, mesmo que para município diverso.

Reconhecendo tratar-se de **substancial alteração da jurisprudência do TSE** (o que o Min. Gilmar Mendes denominou “viragem jurisprudencial”), o STF resolveu **modular** os efeitos da decisão, no sentido da técnica da aplicabilidade prospectiva das decisões, tendo em vista os **princípios da segurança jurídica**, da **anterioridade eleitoral** (art. 16, CF/88) e da **confiança**, “a fim de proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que, de alguma forma, participassem dos prélios eleitorais” (*Inf. 673/STF*).

Conforme decidiu o STF, a **proibição da figura do “prefeito itinerante”** passa a ser o **novo entendimento**, aplicável, no entanto, a partir de 2012.

■ 17.4.1.2.1.3. ***Inelegibilidade relativa em razão da função para concorrer a outros cargos***

O art. 14, § 6.º, estabelece que, para concorrer a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até **6 meses** antes do pleito.

Trata-se do instrumento da **desincompatibilização**, através do qual o

candidato (cidadão) se desvencilha de alguma circunstância que o impede de exercer a sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, de eleger-se para determinado cargo.

Resta saber se a expressão “outros cargos” se aplica somente a cargos diversos (diferentes, “outros”), ou se engloba, também, a reeleição para o mesmo cargo, por exemplo, a reeleição do Presidente da República. Teria ele de renunciar 6 meses antes do pleito para concorrer ao mesmo cargo?

Entendemos que sim, pela própria natureza e finalidades das inelegibilidades, quais sejam, a proteção da probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração (art. 14, § 9.º). [16](#)

CUIDADO: esse não é o entendimento do STF, que se manifestou no sentido de que a **desincompatibilização** deve dar-se somente para a candidatura a **outros cargos, diversos, diferentes. Para a reeleição, os Chefes do Executivo não precisam, portanto, renunciar 6 meses antes do pleito.** [17](#)

Finalmente, em relação aos vices, a mencionada regra da desincompatibilização não incide, na medida em que não são mencionados no art. 14, § 6.º, a não ser que tenham, nos 6 meses anteriores ao pleito, sucedido ou substituído os titulares.

■ 17.4.1.2.2. *Inelegibilidade relativa em razão do parentesco*

A ideia da **inelegibilidade relativa em razão do parentesco**, conforme anotou o STF, deve ser interpretada “... de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados **republicanos** e **democráticos** da Constituição, **evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder**” (RE 543.117-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.06.2008, *DJE* de 22.08.2008).

Como regra, então, de acordo com o art. 14, § 7.º, são **inelegíveis**, no **território da circunscrição do titular**, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do:

- Presidente da República;
- Governador de Estado, Território ou Distrito Federal;
- Prefeito;
- ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Em julgamento do *RE 344.882-BA*, interposto contra acórdão do TSE que, “... interpretando o disposto nos §§ 5.º e 7.º do art. 14 da CF, concluíra pela elegibilidade de cunhada e de irmão de prefeito, falecido antes dos 6 meses que antecederam o pleito, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, sob a fundamentação de que, subsistindo a possibilidade, em tese, de reeleição do próprio titular para o período subsequente, seria também legítima a candidatura de seus parentes para os citados cargos eletivos, porquanto ocorrido o falecimento do titular dentro do prazo previsto na CF..., o Min. Sepúlveda Pertence, relator, proferiu voto no sentido de manter o acórdão recorrido, por entender que, após a edição da EC 16/97, o tratamento dispensado ao titular do cargo deve ser o mesmo adotado relativamente aos parentes — ou seja, sendo reelegível o titular, e renunciando 6 meses antes do pleito, permite-se a candidatura de seus parentes ao mesmo cargo...” (*Inf. 283/STF*).

O Plenário do STF, como noticiado, em 07.04.2003, concluiu que “... parentes podem concorrer nas eleições, desde que o titular do cargo tenha o direito à reeleição e não concorra na disputa. A decisão foi por maioria de votos, ficando vencido o Ministro Moreira Alves”. [18](#)

Ainda, nos termos da [SV 18/2009](#), pacificou o STF que “a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7.º do artigo 14 da Constituição Federal”. Buscava-se, acima de tudo, evitar a possibilidade de se fraudar ou burlar a regra constitucional da inelegibilidade, em razão de separações, por vezes, fictícias.

Os precedentes que deram origem à súmula vinculante tratavam apenas de separações de fato, mas **não** em virtude do evento **morte**, situação não analisada pela Corte quando de sua edição.

Em momento seguinte, a amplitude da SV 18/STF veio a ser explicitada pelo STF. Inicialmente, a 2.^a Turma, no julgamento do **AC 3.298-AgR** (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24.04.2013), afastou a sua aplicação diante das particularidades do caso. Na situação concreta, o Prefeito do **Município de Pombal/PB** havia falecido há mais de 1 ano antes do término de seu mandato, tendo sido sucedido pelo Vice. Na eleição subsequente, de 2008, a ex-cônjuge do Prefeito falecido foi eleita Chefe do Executivo do mesmo município. No curso do primeiro mandato, a viúva constituiu novo núcleo familiar, com novo casamento civil e religioso e com filhos dessa nova união. No pleito seguinte, candidatou-se e foi eleita em 2012. Em consulta respondida no mesmo ano, o TSE entendeu que não haveria violação ao art. 14, § 7.º. Contudo, em razão de impugnação da candidatura pela coligação adversária, a Justiça Eleitoral decidiu pela inelegibilidade. Contra essa decisão do TSE foi interposto recurso extraordinário e, também, medida cautelar diretamente no STF para se dar o efeito suspensivo (requerendo o afastamento excepcional das Súmulas 634 e 635/STF). Em janeiro de 2013, o Min. Lewandowski, no exercício da presidência, determinou a manutenção da prefeita eleita no cargo. Contra essa decisão foi interposto o agravo regimental. No referido julgamento, cautelarmente, a 2.^a T. do STF confirmou a manutenção da prefeita no cargo por vislumbrar o afastamento da SV 18.

Posteriormente, essa tese vencedora proferida na medida cautelar veio a ser **ratificada** pelo **Plenário** do STF quando do julgamento do referido recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que havia indeferido o registro da candidatura. Segundo estabeleceu a Corte, “o que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a **dissolução fraudulenta** ou **simulada** de **sociedade conjugal** seja utilizada como mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa prevista no § 7.º do art. 14 da Constituição. Portanto, **não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges**” (**RE 758.461**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22.05.2014, Plenário, *DJE* de 30.10.2014 — *tema 678* da repercussão geral/STF).

■ 17.4.1.2.3. Militares

Prevê expressamente o art. 14, § 8.º, que o militar **alistável** é **elegível**. Para tanto, deverá atender às seguintes condições:

■ **menos de 10 anos de serviço**: deverá afastar-se da atividade;

■ **mais de 10 anos de serviço**: será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a **inatividade**.

Esses dispositivos foram interpretados pelo STF no julgamento do **RE 279.469**.

No caso concreto, determinado militar, com **menos de 10 anos de serviço**, portanto, enquadrado na hipótese do **art. 14, § 8.º, I**, após ter o seu registro de candidatura deferido, foi **demitido** pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul.

Contra referido ato coator, o militar impetrou mandado de segurança e o TJ/RS **anulou** a demissão *ex officio*.

O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, interpôs recurso extraordinário e o STF, ao final, por maioria de votos, **deu provimento ao recurso, restabelecendo a demissão do militar**.

Para o STF, os militares devem ser diferenciados de acordo com o tempo de serviço.

Na hipótese de contar com **menos de 10 anos de serviço**, embora o texto diga apenas que o militar deverá **afastar-se**, esse afastamento deve ser entendido como **definitivo**.

Assim, ao se candidatar a cargo eletivo, o militar com menos de 10 anos será **excluído do serviço ativo** mediante **demissão** ou **licenciamento ex officio** e o consequente **desligamento da organização** a que estiver vinculado.

No entanto, se o militar contar com **mais de 10 anos de serviço** (art. 14, § 8.º, II), será **agregado** (afastado temporariamente) pela autoridade superior e, se

eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a **inatividade**.

Nesse sentido, pedimos vênia para transcrever a ementa do referido acórdão:

“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Militar alistável. Elegibilidade. Policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com **menos de 10 (dez) anos de serviço**. Candidatura a mandato eletivo. **Demissão oficial por conveniência do serviço**. Necessidade de **afastamento definitivo**, ou **exclusão do serviço ativo**. Pretensão de reintegração no posto de que foi exonerado. Inadmissibilidade. Situação diversa daquela ostentada por militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício. Mandado de segurança indeferido. Recurso extraordinário provido para esse fim. Interpretação das disposições do art. 14, § 8.º, I e II, da CF. Voto vencido. **Diversamente do que sucede ao militar com mais de dez anos de serviço, deve afastar-se definitivamente da atividade, o servidor militar que, contando menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo**” (RE 279.469, Rel. p/ o ac. Min. Cezar Peluso, j. 16.03.2011, Plenário, DJE de 20.06.2011).

■ 17.4.1.2.4. *Inelegibilidades previstas em lei complementar*

De acordo com o art. 14, § 9.º, da CF/88, **lei complementar** estabelecerá **outros casos de inelegibilidade** e os **prazos de sua cessação**, a fim de que sejam protegidos os preceitos da:

- probidade administrativa;
- moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato;
- normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Assim, segundo regra explícita na Constituição, o instrumento para o estabelecimento de outros casos de inelegibilidade só poderá ser a **lei complementar**, no caso a **LC n. 64/90**, sob pena de incorrerem em inconstitucionalidade (formal).

Outrossim, na medida em que se trata de **restrições a direitos fundamentais**, somente novas **inelegibilidades relativas** poderão ser definidas, já que as **absolutas** só se justificam quando previstas pela CF e, em nosso entender, pelo poder constituinte originário, sob pena de se ferirem direitos e garantias individuais (art. 60, § 4.º, IV).

Podemos distinguir, portanto, do ponto de vista formal, o procedimento para a disciplina dos **requisitos de elegibilidade** e, em outro sentido, as situações de **inelegibilidade**, o que bem anota o STF:

“O domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária, constituindo condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3.º), revelam-se passíveis de válida disciplinação mediante simples **lei ordinária**. Os requisitos de **elegibilidade** não se confundem, no plano jurídico-conceitual, com as hipóteses de **inelegibilidade**, cuja definição — além das situações já previstas diretamente pelo próprio texto constitucional (CF, art. 14, §§ 5.º a 8.º) — só pode derivar de norma inscrita em **lei complementar** (CF, art. 14, § 9.º)” (ADI 1.063-MC).

Dois importantes precedentes merecem menção, consagrando o entendimento de **dispensa** de lei complementar por **não** se tratar de hipótese de inelegibilidade:

■ **Captação de sufrágio:** “Art. 41-A da Lei n. 9.504/97. Captação de sufrágio. As sanções de cassação do registro ou do diploma previstas pelo art. 41-A da Lei n. 9.504/97 **não constituem novas hipóteses de inelegibilidade**” (ADI 3.592);

■ **Proibição de inauguração de obra três meses antes do pleito:** “(...) O preceito inscrito no art. 77 da Lei federal n. 9.504 visa a coibir abusos, conferindo igualdade de tratamento aos candidatos, sem afronta ao disposto no art. 14, § 9.º, da Constituição do Brasil. A alegação de que o artigo impugnado violaria o princípio da isonomia improcede...” (ADI 3.305).

Lembramos, ainda, em relação às inelegibilidades, as novidades introduzidas pela **LC n. 135/2010** (“Lei da Ficha Limpa”), consideradas **constitucionais** pelo STF no julgamento conjunto das **ADCs 29 e 30** e da **ADI 4.578**. É o que

desenvolvemos a seguir.

■ 17.4.2. Candidatos com “ficha suja”: inelegibilidade?

Conforme acabamos de estudar, uma das hipóteses de **inelegibilidade relativa** decorre de **lei complementar** nos termos do § 9.º do art. 14, que pedimos, novamente, vênha para reproduzir:

“Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a **probidade administrativa**, a **moralidade** para o exercício do mandato, considerada a **vida pregressa do candidato**, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.

Deve-se, pois, analisar o sentido da expressão **“vida pregressa do candidato”**.

Para tanto consultamos a **LC n. 64/90**, com regras importantes trazidas pela **LC n. 135, de 04.06.2010** (“Lei da Ficha Limpa”).

Antes das modificações, para que se caracterizasse uma das hipóteses de inelegibilidade era necessário que houvesse sentença negativa **transitada em julgado**.

Ainda à luz da regra antiga, que exigia expressamente o trânsito em julgado, em 26.06.2008 a **AMB** — Associação dos Magistrados Brasileiros propôs a **ADPF 144** contra a interpretação do TSE, sustentando ser desnecessário o **trânsito em julgado** da ação para que se caracterizasse a inelegibilidade.

Segundo a AMB, a Justiça Eleitoral deveria reconhecer a inelegibilidade pelo simples fato de haver ação judicial proposta em face do candidato a demonstrar atitude ímproba e imoral.

Em 06.08.2008, no entanto, por 9 x 2 e depois de quase 8 horas de julgamento, o STF negou o pedido da AMB.

Ao entender que o art. 14, § 9.º, não é autoaplicável (Enunciado n. 13 da Súmula do TSE), reconheceu o STF que, necessariamente, será a lei

complementar que disciplinará as hipóteses de inelegibilidade.

A simples “ficha suja”, o mero apontamento e desenvolvimento de uma ação judicial, sem o trânsito em julgado, **não era suficiente**, portanto, para caracterizar a inelegibilidade.

CUIDADO: inovando, contudo, a referida **LC n. 135/2010** passou a definir, com mais precisão, o conceito de *vida pregressa do candidato*, dando maior “peso” a eventual “ficha suja”.

Dentre as novidades, podemos citar a hipótese de inelegibilidade não somente no caso de decisão transitada em julgado por crime praticado, como, também, em razão de decisão proferida, na hipótese dos crimes elencados, por **órgão judicial colegiado**, mesmo que ainda **não tenha ocorrido o trânsito em julgado**.

A LC n. 135/2010, inovando, tornou **inelegível** aquele que for condenado, em decisão transitada em julgado ou **proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral**, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma.

A grande questão inicial era saber se as novidades deveriam ser aplicadas imediatamente, no caso, às eleições de 2010, alegando alguns candidatos violação ao **princípio da anualidade eleitoral**, ou seja, ao art. 16 da CF/88, ao estabelecer que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra em até 1 ano da data de sua vigência.

Em seguida, definido o momento de sua aplicação, a outra discussão envolvia a análise da constitucionalidade ou não da denominada **“Lei da Ficha Limpa”**.

Em relação à primeira preocupação, chegamos a sustentar, em edições anteriores, que as hipóteses de inelegibilidade relativa ampliadas pela “Lei da Ficha Limpa” não se caracterizavam como processo eleitoral, mas, de fato, como **norma eleitoral material**, não influenciando o processo eleitoral, e, portanto, de aplicação imediata (nesse sentido, cf. CTA n. 112.026/DF — TSE,

10.06.2010).

Isso porque, na linha do que já havia decidido o STF, os seus preceitos (cf. ADI 3.345, Min. Celso de Mello, j. 25.08.2005):

- **não rompem a igualdade de participação dos partidos e candidatos;**
- **não afetam a normalidade das eleições;**
- **não perturbam o pleito;**
- **não ensejam alteração motivada por propósito casuístico.**

O TSE decidiu, também, que a LC n. 135/2010 se aplicava a situações anteriores, por não constituir pena (CTA n. 114.709/DF, j. 17.06.2010).

Em 25.08.2010, o TSE, no julgamento do RO 4.336-27, confirmou a **aplicação imediata** da nova regra e a possibilidade de retroagir, atingindo candidatos condenados por órgão colegiado antes de sua vigência.

Diante das decisões da Corte eleitoral, a matéria foi parar no STF, que, em sua primeira análise, em razão de empate em 5 x 5, no julgamento do **RE 631.102**, em 27.10.2010, não resolveu a questão da regra do art. 16.

A Corte, à época, não utilizou a previsão do chamado *voto de qualidade*, que seria a opção para o Ministro Presidente resolver a pendência. Ainda, como não se atingiu o *quorum* do art. 97 (maioria absoluta, ou seja, no mínimo 6 votos), aplicando-se analogicamente o art. 205, parágrafo único, II, do RI/STF, a lei continuou com a sua presunção de constitucionalidade, prevalecendo, então, a decisão do TSE.

Em 02.02.2011, a Presidente Dilma Rousseff indicou o 11.º Ministro do STF, Luiz Fux, para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do Min. Eros Grau e, então, com 11 Ministros, a questão podia, finalmente, ser resolvida.

Deixamos a nossa crítica em razão da **demora** na nomeação, acarretando a realização das eleições de outubro/2010 sem a definição dessa questão extremamente importante.

Enfim, em **23.03.2011**, o STF determinou, por 6 x 5, agora no julgamento do **RE 633.703**, o **afastamento** da incidência da LC n. 135/2010 para as eleições já

ocorridas em 2010 e as anteriores, bem como para os mandatos em curso, sob pena de se violar o art. 16 da CF/88, que, consagrando o princípio da **anterioridade eleitoral**, assegura o **devido processo legal eleitoral**.

Segundo a Corte, o art. 16 tem por escopo evitar mudanças no sistema eleitoral, garantindo a **igualdade de chances** no pleito eleitoral e, nesse sentido, a **proteção das minorias partidárias**.

A aplicação do art. 16, direito fundamental, caracteriza-se como verdadeira **cláusula pétrea**, não cabendo ao Judiciário, nesse contexto, analisar a moralidade da legislação. Trata-se, em essência, de **“barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria”**.

Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, o art. 16 estabelece verdadeira “garantia fundamental do cidadão-eleitor, do cidadão-candidato e dos partidos políticos (...) oponível, inclusive, em relação ao exercício do poder constituinte derivado”. Dessa forma, na medida em que a LC n. 135/2010 interferiu “... em fase específica do processo eleitoral — fase pré-eleitoral —, a qual se iniciaria com a escolha e a apresentação de candidaturas pelos partidos políticos e encerrar-se-ia até o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral”, não poderia ser aplicada às eleições de 2010 (cf. *Inf. 620/STF* e **RE 633.703**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.03.2011, Plenário, *DJE* de 17.11.2011).

Resolvida a primeira questão, isto é, a aplicação do art. 16, restava analisar a constitucionalidade material da **“Lei da Ficha Limpa”**.

Em nosso entender, a **LC n. 135/2010** encontra total respaldo no art. 14, § 9.º, definindo o conceito de **“vida pregressa do candidato”** e, assim, opta por inadmitir aqueles que possam colocar em risco a probidade e a moralidade administrativa, em verdadeira consagração ao **princípio da precaução**, do **Estado Democrático de Direito** e da **República**, esta última enquadrada como princípio sensível da Constituição.

Nesse sentido, o STF, em 16.02.2012, por maioria, no julgamento conjunto das **ADCs 29 e 30** e da **ADI 4.578**, entendeu que a *Lei da Ficha Limpa* é **constitucional** e pode ser aplicada, inclusive, a atos e fatos ocorridos anteriormente à sua edição, tendo sido observada já nas eleições de 2012.

Dentre os vários aspectos do acórdão de **375 páginas** (e que vale a leitura!), podemos destacar o reconhecimento da observância das exigências de moralidade e probidade no tocante à vida pregressa, bem como a *interpretação conforme a Constituição* das alíneas “e” e “f” do inciso I do art. 1.º da LC n. 64/90, na redação dada pela LC n. 135/2010, para **admitir** a redução de tempo que transcorreu entre a condenação e o seu trânsito em julgado do prazo de 8 anos de inelegibilidades após o cumprimento da pena (**detração**). Vejamos:

“EMENTA: (...) 2. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de **moralidade** para o exercício do mandato (art. 14, § 9.º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional.

3. A presunção de inocência consagrada no art. 5.º, LVII, da Constituição Federal deve ser reconhecida como uma regra e interpretada com o recurso da metodologia análoga a uma redução teleológica, que reaproxime o enunciado normativo da sua própria literalidade, de modo a **reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação criminal** (que podem incluir a perda ou a suspensão de direitos políticos, mas não a inelegibilidade), sob pena de frustrar o propósito **moralizante** do art. 14, § 9.º, da Constituição Federal.

4. **Não é violado** pela Lei Complementar n. 135/2010 o **princípio constitucional da vedação de retrocesso**, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral.

(...).

12. A extensão da inelegibilidade por 8 anos após o cumprimento da pena, admissível à luz da disciplina legal anterior, **viola a proporcionalidade** numa sistemática em que a interdição política se põe já antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação conforme a Constituição, **deduzir do prazo posterior ao cumprimento da pena o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado**”

([ADC 29](#); [ADC 30](#) e [ADI 4.578](#), Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.02.2012, Plenário, DJE de 29.06.2012).

■ 17.4.3. Privação dos direitos políticos — perda e suspensão

Já vimos as regras que restringem a [elegibilidade](#) do cidadão, tornando-o inelegível, absoluta ou relativamente. Agora, verificaremos as situações que privam o cidadão dos direitos políticos de votar e ser votado, tanto definitivamente (perda) como de modo temporário (suspensão).¹⁹ Em [nenhuma hipótese](#), ressalte-se, será permitida a [cassação de direitos políticos](#).

■ 17.4.3.1. Perda dos direitos políticos (arts. 15, I e IV, e 12, § 4.º, II, da CF/88)

■ [Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado](#): em decorrência do cancelamento da naturalização, o indivíduo voltará à condição de estrangeiro, não mais podendo se alistar como eleitor (art. 14, § 2.º) nem eleger-se, uma vez que deixa de ostentar a nacionalidade brasileira (art. 14, § 3.º, I).

■ [Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa](#): o art. 5.º, VIII, estabelece, como regra, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. No entanto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (ex.: serviço militar obrigatório — cf. art. 143) e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, terá, como sanção, a declaração da perda de seus direitos políticos.

Sobre essa hipótese, alertamos que a maioria dos autores de direito eleitoral vem entendendo como situação de [suspensão](#), e não de perda de direitos políticos, nos termos da literalidade do art. 4.º, § 2.º, da Lei n. 8.239/91.

Apenas nos alinhamos ao conceito de *perda*, com José Afonso da Silva, já que para readquirir os direitos políticos a pessoa precisará tomar a decisão de prestar o serviço alternativo, não sendo o vício suprimido por decurso de prazo.

■ **Perda da nacionalidade brasileira em virtude de aquisição de outra:** embora não conste dos incisos do art. 15 da CF, mediante interpretação sistemática pode-se elencar o descrito no art. 12, § 4.º, II, da CF como mais uma hipótese constitucionalmente prevista de **perda dos direitos políticos**. Isso porque a **nacionalidade brasileira é pressuposto para a aquisição de direitos políticos**. Perdendo a nacionalidade brasileira e adquirindo outra, o ex-brasileiro passa a ser **estrangeiro** e, como vimos, os estrangeiros, bem como os conscritos, durante o serviço militar obrigatório (só para lembrar o candidato atento e estudioso!), são **inalistáveis** (quem não pode ser eleitor não pode eleger-se). O alistamento eleitoral, como vimos, é indiscutível condição de elegibilidade. Assim e por todo o exposto, como o estrangeiro **não adquire direitos políticos**, exclusivos de brasileiros natos ou naturalizados, a perda da nacionalidade gera a indiscutível perda dos direitos políticos, outrora existentes.

■ **17.4.3.2. Suspensão dos direitos políticos (arts. 15, II, III e V, e 55, II, e § 1.º, da CF/88; art. 17.3 do Dec. n. 3.927/2001 c/c o art. 1.º, I, “b”, da LC n. 64/90)**

■ **incapacidade civil absoluta:** como só se pode suspender aquilo que já existia, deve-se partir do pressuposto de que o indivíduo tinha direitos políticos e estes foram suspensos. Então, somente nos casos de interdição é que se poderia falar em suspensão de direitos políticos;

■ **condenação criminal transitada em julgado:** observar que os direitos políticos ficam **suspensos** enquanto durarem os efeitos da condenação; [20](#)

■ **improbidade administrativa nos termos do art. 37, § 4.º:** os atos de improbidade administrativa, portanto, importarão a **suspensão dos direitos políticos**, bem como a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Observar que a declaração da improbidade terá de ser via processo judicial, não podendo dar-se através de mero processo administrativo. Segundo *José Afonso da Silva*, “a improbidade diz respeito à prática de ato que gere prejuízo ao erário público em proveito do agente. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada pelo dano ao erário

e correspondente vantagem ao ímprobo. O ímprobo administrativo é o devasso da Administração pública”;[21](#)

■ **exercício assegurado pela cláusula de reciprocidade (art. 12, § 1.º):** na dicção do art. 17.3 do Decreto n. 3.927/2001 (*Promulga o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, celebrado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000*), “o gozo de direitos políticos no Estado de residência importa na suspensão do exercício dos mesmos direitos no Estado da nacionalidade”. Assim, o gozo dos direitos políticos em Portugal (por brasileiro) importará na suspensão do exercício dos mesmos direitos no Brasil;

■ **art. 55, II, e § 1.º, c/c o art. 1.º, I, “b”, da LC n. 64/90:** procedimento do Deputado ou Senador declarado incompatível com o decoro parlamentar — inelegibilidade por 8 anos (art. 1.º, I, “b”, da LC n. 64/90).

■ 17.4.4. Reaquisição dos direitos políticos perdidos ou suspensos

Perdido o direito político, na hipótese de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, a reaquisição só se dará por meio de ação rescisória.

Se a hipótese for a **perda** por recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, a reaquisição dar-se-á quando o indivíduo, a qualquer tempo, cumprir a obrigação devida.

Todavia, se a **perda** se der em virtude de aquisição de outra nacionalidade, o art. 36 da Lei n. 818/49 prevê a possibilidade de reaquisição por decreto presidencial, se o ex-brasileiro estiver domiciliado no Brasil. Entendemos, contudo, que tal dispositivo só terá validade se a reaquisição não contrariar os dispositivos constitucionais e, ainda, se existirem elementos que atribuam nacionalidade ao interessado.[22](#)

No tocante às hipóteses de **suspensão**, a reaquisição dos direitos políticos dar-se-á quando cessarem os motivos que a determinaram.

■ 17.5. SERVIDOR PÚBLICO E EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO

De acordo com o **art. 38** da CF, na redação dada pela EC n. 19/98, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no **exercício de mandato eletivo**, aplicam-se as seguintes disposições:

- tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará **afastado** de seu cargo, emprego ou função;
- investido no mandato de **Prefeito**, será **afastado** do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**;
- investido no mandato de **Vereador**, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
- em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
- para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

■ 17.6. QUESTÕES

1. (MP/SP/80.º/1998) No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, o plebiscito constitui consulta popular prévia sobre matéria política ou institucional, antes de sua formulação legislativa, enquanto o referendo constitui consulta posterior à aprovação de projeto de lei ou de emenda constitucional, para ratificação ou rejeição, configurando um e outro instrumento de exercício da soberania popular. As noções conceituais de plebiscito e referendo aqui expendidas:

- a) estão corretas, aduzindo-se que a convocação do plebiscito é de competência concorrente do Presidente da República e do Congresso Nacional.
- b) estão corretas, mas não se relacionam com o exercício da soberania popular.
- c) estão corretas, aduzindo-se que a convocação do plebiscito é privativa do Presidente da República.

- d) estão invertidas no que se relaciona ao momento de sua ocorrência, pois o referendo antecede a deliberação parlamentar, e o plebiscito a sucede.
- e) estão corretas, aduzindo-se que a autorização de referendo e a convocação de plebiscito são da competência exclusiva do Congresso Nacional.

2. (Magistratura/SP/178.º — 2006) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional:

- a) resolver definitivamente, em qualquer caso, sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
- b) autorizar referendo e convocar plebiscito.
- c) autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.
- d) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

3. (Notário/SP/2006) Assinale a alternativa correta: a Constituição Federal estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce mediante representantes eleitos, ou diretamente, por meio do:

- a) referendo, do *habeas corpus* e da ação popular.
- b) referendo, da ação popular e do plebiscito.
- c) mandado de injunção e da iniciativa popular.
- d) plebiscito, do referendo e da iniciativa popular.

4. (50.º MP/MG — 2010) Dentre as formas diretas de exercício da soberania popular, podemos apontar, EXCETO:

- a) a reclamação constitucional.
- b) o plebiscito.
- c) o referendo.
- d) a iniciativa popular.

5. (Procurador Autárquico — DER-RO — FUNCAB/2010) Pedro Lenza anota que, no magistério de J. J. Gomes Canotilho, este festejado autor português identifica a existência de vários “movimentos constitucionais”, como o inglês, o americano e o francês, definindo o constitucionalismo como uma “...teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade.”

Assinale a alternativa correta:

- a) O totalitarismo constitucional é vedado pela Constituição Federal de 1988, pois impede o florescer da constituição dirigente defendida por Canotilho.
- b) A Constituição Federal de 1988 não contemplou a democracia participativa, pois estabeleceu que todo o poder emana do povo e por ele será exercido por meio de representantes eleitos.
- c) A democracia direta é prevalente sobre a democracia representativa, constituindo um sistema híbrido, aplicável conforme a Constituição Federal de 1988.
- d) O resultado de plebiscito ou referendo tem natureza de consulta popular e não é vinculante, podendo o Congresso Nacional editar lei ou Emenda Constitucional em sentido contrário.
- e) A competência para autorizar um referendo é do Congresso Nacional, mas somente o Presidente da República pode convocar um plebiscito.

6. (MP/80.º) Aponte, no rol de consequências adiante, aquela que, segundo as normas constitucionais, não se relacionam com a prática de atos de improbidade administrativa:

- a) perda da função pública;
- b) perda da nacionalidade;
- c) indisponibilidade dos bens;
- d) ressarcimento ao erário;
- e) suspensão dos direitos políticos.

7. (OAB/108.º) Poderá um estrangeiro, naturalizado brasileiro, candidatar-se ao Senado Federal?

- a) sim, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros, em seu país de origem;
- b) sim, não podendo apenas ser eleito presidente daquela casa;
- c) sim, desde que o Regimento Interno do Senado não o proíba;
- d) sim, desde que a lei eleitoral não faça distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados.

8. (MP/81.º/2.ª Prova) Assinale a opção em que não há erro, no que se refere às consequências advindas do exercício de mandato eletivo por parte de servidor público.

- a) tratando-se de mandato de deputado federal, ficará afastado do cargo, emprego ou função;
- b) tratando-se de mandato de deputado estadual ou distrital, poderá optar entre afastar-se ou não;
- c) tratando-se de mandato de prefeito, o afastamento será obrigatório, vedada a faculdade de optar pelos vencimentos de servidor;
- d) tratando-se de mandato de vereador, não havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
- e) tratando-se de mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, aplicar-se-á a norma da alternativa “b”.

9. (OAB/115.º) Estará legitimado a concorrer ao cargo de Deputado Federal:

- a) o religioso que se recusou a prestar obrigação alternativa, nos termos do art. 143, § 1.º, da Constituição Federal;
- b) o conscrito, no período do serviço militar obrigatório;
- c) o natural de Portugal, com residência permanente no País;
- d) o brasileiro nato, maior de 21 anos, analfabeto.

10. (TJ DF 2007/Questão 1) Nos termos do que preconizado na Constituição de República de 1988, a respeito dos Direitos Políticos, é falso afirmar:

- a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular;
- b) O alistamento eleitoral e voto são facultativos para os analfabetos;
- c) São inelegíveis os inalistáveis;
- d) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da proclamação do resultado, instruída a ação com provas de abuso de poder político, corrupção ou fraude.

11. (TJ MG 2006-EJEF) Constitui condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de:

- a) vinte e um anos para Vereador;
- b) vinte e um anos para Juiz de Paz;

- c) vinte e cinco anos para Governador;
- d) vinte e cinco anos para Deputado Distrital.

12. (TJ MG 2007-EJEF) A perda dos direitos políticos se dará no seguinte caso:

- a) improbidade administrativa.
- b) cancelamento da naturalização, por sentença transitada em julgado.
- c) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
- d) incapacidade civil absoluta.

13. (MPU 2007 FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito dos Direitos Políticos previstos na Carta Magna:

- I. É condição de elegibilidade para o cargo de Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal possuir a idade mínima de trinta e cinco anos.
- II. Para concorrerem a outros cargos os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
- III. São inelegíveis, em qualquer hipótese, no território de jurisdição do titular, os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, do Presidente da República.
- IV. É condição de elegibilidade para o cargo de Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital possuir a idade mínima de vinte e um anos.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

14. (Notários PR 2007) A capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva integram os direitos políticos e são delimitadores do seu exercício. Em face dessa realidade, assinale a correta:

- a) A inelegibilidade relativa decorre do texto constitucional e da lei.
- b) A inelegibilidade absoluta pode ser fixada na lei infraconstitucional.
- c) A capacidade eleitoral ativa compreende as inelegibilidades absolutas.
- d) A inelegibilidade reflexa por motivos de casamento somente fica afastada no caso de o candidato já estar ocupando mandato eletivo e independe de desincompatibilização.

e) Os partidos políticos não possuem direito a recursos do fundo partidário.

15. (MPE/RR/CESPE/UnB-2008) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. O controle administrativo corresponde ao exame que a administração pública faz sobre a sua conduta, quanto à legalidade ou ao mérito de seus atos, por iniciativa própria ou mediante provocação.

16. (Delegado-TO/CESPE/UnB-2008) Em nenhuma hipótese o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou de prefeito municipal, podem ser candidatos a cargos eletivos no território de jurisdição do titular.

17. (TRT/SP/FCC-2008) A capacidade eleitoral passiva é concernente ao direito político classificado por

- a) participação partidária.
- b) alistabilidade.
- c) elegibilidade.
- d) plebiscito.
- e) referendo.

18. (Analista Judiciário Maranhão UnB/CESPE-2009) Artur, com 17 anos de idade, registrou-se como eleitor e filia-se tempestivamente a um partido político para concorrer ao cargo de vereador. Nessa situação hipotética, em face das disposições constitucionais e legais a respeito da candidatura, Artur:

- a) deverá ter sua candidatura declarada ilegal, em qualquer situação, pois a idade mínima, no caso, é de 21 anos de idade.
- b) poderá ser legalmente considerado candidato somente se for emancipado pelos pais ou responsável.
- c) poderá tomar posse no cargo, desde que tenha completado 18 anos de idade até a data da posse no cargo.
- d) deverá ter sua candidatura negada pela justiça eleitoral, por não cumprir exigência constitucional de idade mínima.
- e) somente será legalmente considerado candidato se completar 18 anos de idade até a data da eleição.

19. (Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais/FUMARC — 2009) Dentre os instrumentos da democracia semidireta, aquele que consiste em consulta à opinião do eleitorado sobre a manutenção ou a revogação do mandato político ou administrativo conferido a alguém, denomina-se:

- a) *Impeachment*.
- b) Plebiscito.
- c) Referendo.
- d) *Recall*.
- e) Mandato imperativo.

20. (Delegado de Polícia RJ/CEPERJ — 2009) Com relação ao atual texto expresso da Constituição da República analise as seguintes proposições:

- I. A iniciativa popular, expressão do exercício de soberania popular, pode ser realizada através de apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- II. Podem alistar-se como eleitores, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
- III. Partidos políticos que se propõem a disputar apenas eleições estaduais devem registrar os seus estatutos perante o Tribunal Regional Eleitoral da correspondente unidade da Federação.
- IV. Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima são condições de elegibilidade, previstas expressamente no texto da atual Constituição da República.
- V. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, e improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4.º, da CR, são hipóteses de incidência de suspensão dos direitos políticos.

Assinale a alternativa que corresponde à relação completa de proposições corretas:

- a) I, IV e V.
- b) I, II e V.
- c) III, IV e V.
- d) II, IV e V.
- e) II, III e IV.

21. (Técnico Judiciário — área administrativa — TRT/9.^a Região — FCC 2010) No

tocante aos Direitos Políticos, considere as seguintes assertivas:

- I. O alistamento eleitoral é obrigatório para o analfabeto.
- II. O voto é obrigatório para o analfabeto.
- III. Os conscritos não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório.
- IV. Os analfabetos são inelegíveis.
- V. É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de dezoito anos para vereador.

Está INCORRETO o que consta APENAS em:

- a) I e II.
- b) I, III e IV.
- c) II, IV e V.
- d) III, IV e V.
- e) I, II, III e V.

22. (Procurador do MP junto ao TCE/RO — FCC 2010) Em relação às condições de elegibilidade, é correto afirmar que:

- a) para concorrerem a outros cargos, os Chefes do Poder Executivo e os parlamentares devem renunciar a seus respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
- b) cunhado de Prefeito, que não seja vereador, bem como candidato à reeleição, não poderá concorrer para eleições à vereança nesta mesma circunscrição municipal.
- c) a Constituição vigente permitiu aos analfabetos o direito ao voto e à elegibilidade.
- d) Vice-Presidente da República que tenha assumido o cargo de seu titular definitivamente no máximo seis meses antes do término do mandato poderá disputar a reeleição subsequente como Presidente, e, se eleito, poderá concorrer para o mesmo cargo na próxima eleição.
- e) além dos casos de inelegibilidade expressamente previstos na Constituição, lei ordinária poderá estabelecer outros para a proteção da probidade administrativa.

23. (Técnico Judiciário — TRE/CE — Área Administrativa — FCC/2012) Átila, que não é titular de mandato eletivo e nem é candidato à reeleição, é filho adotivo de Eulália, Governadora do Estado de São Paulo em exercício, e deseja concorrer ao cargo de Prefeito do Município de São Paulo. Segundo a Constituição Federal, Átila, em regra, é:

- a) elegível, desde que esteja filiado ao mesmo partido político de Eulália.
- b) elegível, desde que esteja filiado a partido político distinto de Eulália.
- c) elegível, desde que autorizado previamente pelo Tribunal Regional Eleitoral.
- d) elegível, desde que sua candidatura seja previamente autorizada por Eulália.
- e) inelegível.

24. (Analista de Controle Externo — TCE-AP — Orçamento e Finanças — FCC/2012) Um Governador de Estado, ainda no início do exercício de seu mandato, deseja se candidatar ao cargo de Presidente da República. Para que possa concorrer às eleições e, caso seja vitorioso, assumir o novo cargo, deverá ser brasileiro nato:

- a) e afastar-se temporariamente de seu atual mandato até seis meses antes do pleito.
- b) ou naturalizado e descompatibilizar-se em relação a seu atual mandato até seis meses antes do pleito.
- c) ou naturalizado e renunciar a seu atual mandato até três meses antes do pleito.
- d) e renunciar a seu atual mandato até seis meses antes do pleito.
- e) e afastar-se temporariamente de seu atual mandato até três meses antes do pleito.

25. (Titular de Serviços de Notas e de Registros — TJ-SP — VUNESP/2011) Sobre direitos políticos, é INCORRETO dizer:

- a) o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, mas facultativos se estiverem numa das seguintes condições: (i) analfabetos ou (ii) maiores de setenta anos.
- b) a elegibilidade mínima para quaisquer cargos é de vinte e um anos.
- c) o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
- d) a soberania popular é exercida mediante voto, plebiscito, referendo popular e iniciativa popular.

26. (Técnico Judiciário — TRT-11/AM — Área Administrativa — FCC/2012) Sebastião é governador de um determinado Estado brasileiro e pretende se candidatar à reeleição nas próximas eleições. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Sebastião:

- a) deverá se afastar do cargo até três meses antes do pleito, mas continuará recebendo a respectiva remuneração.

- b) deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.
- c) deverá se afastar do cargo até seis meses antes do pleito, mas continuará recebendo a respectiva remuneração.
- d) deverá renunciar ao seu mandato até três meses antes do pleito.
- e) poderá permanecer no cargo, inexistindo obrigatoriedade de renúncia ao mandato.

27. (Exame de Ordem Unificado.1 — jul./2011 — FGV/2011) Os direitos políticos não podem ser cassados. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento:

- a) condenação cível sem trânsito em julgado.
- b) incapacidade civil relativa, declarada judicialmente.
- c) cancelamento de naturalização por decisão administrativa.
- d) improbidade administrativa.

28. (Procurador do Estado/RO — 2011) No recente julgamento do STF, conhecido como caso “ficha limpa”, a questão central da discussão baseou-se na interpretação do princípio da anualidade, o qual significa que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor:

- a) na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que se realize até um ano da data de sua vigência.
- b) um ano após a sua publicação e só se aplica à eleição realizada após a sua vigência.
- c) na data de sua publicação, com aplicação imediata.
- d) na data estipulada pelo Congresso Nacional, não será aplicada à eleição que se realize até um ano da data de sua vigência.
- e) na data estipulada pelo Superior Tribunal Eleitoral, não se aplicando à eleição que se realize até um ano da data de sua vigência.

29. (Analista Judiciário — TJ/ES — CESPE/UnB/2011 — Conhecimentos Básicos) Em 31 de outubro de 2010, o Brasil elegeu a primeira mulher para o cargo de presidente da República. A respeito das eleições de 2010, julgue o item subsequente:

A campanha eleitoral foi marcada pela incerteza, pois o Tribunal Superior Eleitoral não tomou uma decisão a respeito da Lei da Ficha Limpa.

30. (Analista Judiciário — TRT18 — Oficial de Justiça Avaliador — FCC/2013)

Considere: Estabelece o art. 35, § 1.º, da Lei n. 10.826/03: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6.º desta Lei. § 1.º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. O referendo foi realizado no dia 23.10.2005 com a seguinte questão: O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A apuração dos votos pelo TSE apontou que 63,94% dos eleitores decidiram pela NÃO proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. Logo, após o referendo popular, o art. 35 da Lei 10.826/03 não entrou em vigor. Com base no exemplo apresentado, sob a premissa da Constituição Federal de 1988, no tocante aos princípios fundamentais e direitos políticos, a modificação do resultado deste referendo por Lei ou Emenda Constitucional será:

- a) constitucional, desde que a modificação seja feita por Emenda Constitucional.
- b) inconstitucional por ferir o princípio constitucional da Soberania Popular.
- c) inconstitucional por ferir o princípio constitucional da Separação dos Poderes.
- d) inconstitucional por ferir o princípio constitucional do Pluralismo Político.
- e) constitucional, pois a Lei e a Emenda Constitucional, aprovadas pelo Congresso Nacional, substituem automaticamente o referendo.

■ GABARITO ■

1. “e”. De acordo com o art. 49, XV, da CF/88, podendo ser acrescentado que tanto a autorização de referendo como a convocação de plebiscito se materializam por intermédio de decreto legislativo do Congresso Nacional. Observamos que esta questão foi idêntica na prova da Magistratura de SP/2008. Isso demonstra que a técnica do estudo das questões se apresenta como uma importante ferramenta para a preparação do candidato.

2. “b”. Art. 49, XV. O problema da letra “a”, errada, está na expressão “em qualquer caso”. Percebam que o art. 49, I, da CF/88 fala em instrumentos que “acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. O erro da letra “c” está em generalizar a obrigação, que, no caso, só será necessária para as hipóteses das terras indígenas (art. 49, XVI, c/c o art. 231, § 3.º). Por fim, a competência para a situação da letra “d” é do Senado Federal, e não do Congresso Nacional. Lembre-se de que o CN é bicameral, composto de duas Casas:

Câmara dos Deputados e Senado Federal. A competência exclusiva do CN (art. 49) é distinta da competência da CD (art. 51), que, por sua vez, é distinta da competência do SF (art. 52).
3. “d”. <i>Habeas corpus</i> e mandado de injunção são remédios constitucionais. A ação popular caracteriza-se como forma de participação popular por meio de um processo, assegurando o direito democrático de participação popular do cidadão na vida pública. Parte da doutrina não encontra o seu fundamento no art. 1.º, parágrafo único, não a aceitando como direito político. 23 Contudo, concordando com José Afonso da Silva e Elival da Silva Ramos, para nós a ação popular deve ser encarada como instrumento de democracia direta (o que, no caso da presente prova, permitiria dizer que a letra “b” também seria correta). Como anota José Afonso da Silva, a ação popular “... acolhe um instituto de democracia direta, da mesma natureza da iniciativa popular, do veto popular, do referendo popular, da revocação popular ou do ‘recall’”. Em conclusão: o direito de ação popular encontra seu fundamento no art. 1.º, parágrafo único, da Constituição Federal, na expressão ‘todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição’”. 24
4. “a”.
5. “c”, de acordo com a parte teórica.
6. “b”. Art. 15, V, combinado com o art. 37, § 4.º. Como vimos, uma das hipóteses de suspensão dos direitos políticos dar-se-á no caso de improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4.º, sendo as suas consequências: a suspensão dos direitos políticos (alternativa “e”), a perda da função pública (alternativa “a”), a indisponibilidade dos bens (alternativa “c”) e o ressarcimento ao erário (alternativa “d”). Não se inclui, portanto, a perda da nacionalidade, que se dará nos termos do art. 12, § 4.º.
7. “b”. Art. 14, § 3.º, I, combinado com o art. 12, § 3.º, III.
8. “a”. Art. 38, I, da CF. A letra “b” está errada porque haverá também a necessidade de se afastar do cargo, emprego ou função (art. 38, I); a alternativa “c” traz uma primeira regra correta, qual seja, o necessário afastamento, mas erra ao dizer que é vedada a opção pela remuneração do servidor público (art. 38, II); na letra “d”, o candidato deveria se recordar de que a percepção das vantagens do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, só será permitida se houver compatibilidade de horários (art. 38, III); por fim, a letra “e”, pelos fundamentos acima expostos, está errada (art. 38, III).

9. “c”.
10. “d”. Art. 14, § 10, da CF/88.
11. “b”. Art. 14, § 3.º, VI, “c”, da CF/88.
12. “b”. Art. 15, I, da CF/88.
13. “b”.
14. “a”.
15. “certo”.
16. “errado”. Cf. parte final do art. 14, § 7.º.
17. “c”. Art. 14, § 3.º, da CF/88.
18. “c”.
19. “d”.
20. “a”.
21. “a”.
22. “b”.
23. “e” , nos termos do art. 14, § 7.º. Lembramos, ainda, que, de acordo com o art. 227, § 6.º, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
24. “d” , nos termos do art. 14, § 6.º, devendo ser lembrado, também, o art. 12, § 3.º, I.
25. “b” , por violar o art. 14, § 3.º, VI, “d”, que fala em idade mínima de 18 anos.
26. “e”. Lembrando que a regra do art. 14, § 6.º (desincompatibilização de 6 meses antes do pleito) é para a hipótese de o Chefe do Executivo concorrer a outro cargo, distinto, diverso, e não para o mesmo, na tentativa de reeleição.

27. “d”. Nos termos do art. 15, V. Para as outras alternativas, confira os demais incisos do referido art. 15.
28. “a”, nos termos do art. 16 da CF/88.
29. “errado”. Conforme visto na parte teórica, a indefinição, por nós criticada, era do STF, e não do TSE.
30. “b”. Cf. <i>item 17.1.3.</i>

PARTIDOS POLÍTICOS E O FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS

■ 18.1. CONCEITO

Partido político pode ser conceituado como uma “... organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo ou, ao menos, de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposição”.[1](#)

Para José Afonso da Silva, partido político “... é uma agremiação de um grupo social que se propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. No dizer de Pietro Virga: ‘são associações de pessoas com uma ideologia ou interesses comuns, que, mediante uma organização estável (*Partei-Apparati*), miram exercer influência sobre a determinação da orientação política do país’”.[2](#)

■ 18.2. REGRAS CONSTITUCIONAIS

A primeira regra refere-se à **liberdade de organização partidária**, visto ser livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos (sobre a fusão de partidos políticos, cf. **Lei n. 13.107/2015**).

Não se trata de liberdade partidária absoluta, no entanto, uma vez que

deverão ser resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

- caráter nacional;
- proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
- prestação de contas à Justiça Eleitoral;
- funcionamento parlamentar de acordo com a lei;
- vedação da utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Assegura-se aos partidos políticos **autonomia** para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo constar dos estatutos partidários normas a respeito da fidelidade e disciplina partidárias, podendo, inclusive, prever sanções (como advertência, exclusão...) em caso de **infidelidade partidária** (desrespeito às regras dos estatutos, objetivos, diretrizes, ideais...), não podendo nunca, porém, ensejar a perda do mandato, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 15 da CF, que **repudia**, de forma expressa, a **cassação de direitos políticos**.

Em relação a esse assunto, o STF, “... por maioria, deferiu medida liminar em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República para suspender, até decisão final da ação, o § 1.º do art. 8.º da Lei n. 9.504/97, que assegura aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Considerou-se que a norma atacada ofende, à primeira vista, o **princípio da autonomia dos partidos políticos**, previsto no art. 17, § 1.º, da CF (...). Os Ministros Ellen Gracie e Maurício Corrêa deferiram a cautelar com fundamento mais extenso, qual seja, a aparente ofensa ao princípio da igualdade entre os detentores de mandato eletivo e os integrantes do partido. Vencido o Min. Ilmar Galvão, que indeferia a medida liminar, por entender que o referido dispositivo estabelece a conciliação entre a autonomia

dos partidos e o direito do filiado que, abandonando sua vida profissional, se dedica ao exercício de mandatos” (*Inf. 265/STF, ADI 2.530*). Portanto, com esse entendimento, fica suspensa a denominada “**candidatura nata**” (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

A **constituição** dos partidos políticos consolida-se na forma da lei civil, perante o **Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas** competente (na Capital Federal, Brasília — art. 8.º da Lei n. 9.096/95) e, posteriormente, já tendo adquirido a personalidade jurídica, formaliza-se com o registro de seus estatutos perante o TSE.

Não obstante haja a necessidade de registro perante o TSE, órgão de natureza pública, essa formalidade não atribui a mesma natureza aos partidos políticos, já que sua constituição não obedece às regras básicas de constituição da pessoa jurídica de direito público, quais sejam, a criação por lei e a inexistência de registro de seus instrumentos constitutivos.

Definitivamente, os partidos políticos são verdadeiras **instituições, pessoas jurídicas de direito privado**, na medida em que a sua constituição se dá de acordo com a **lei civil**, no caso a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73).³

Essa regra é corroborada pelos arts. 45 e 985 do Código Civil de 2002, que, trazendo disposições gerais, fixa o início da existência legal das **pessoas jurídicas de direito privado** com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. O art. 120 da Lei de Registros Públicos, lei especial, estabelece os requisitos específicos.

Vale lembrar que o ato do TSE que analisa o pedido de registro partidário **não tem caráter jurisdicional**, mas, conforme asseverou o STF, tem natureza **meramente administrativa**. Por esse motivo, o STF entendeu que, em razão da inexistência do caráter jurisdicional contra a decisão do TSE, não caberia a interposição de recurso extraordinário (RE 164.458-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 27.04.1995, *DJ* de 02.06.1995).

É de observar, também, que os partidos políticos, uma vez constituídos e com

registro perante o TSE, têm **direito** a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (art. 17, § 3.º), sendo beneficiados pela **imunidade tributária** prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, nos seguintes termos: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir imposto sobre o **patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações**”.

■ 18.3. INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA — PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS MINORIAS

O STF, ao julgar as ADIs 1.351 e 1.354, entendeu inconstitucionais os dispositivos da Lei n. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) que instituíram a chamada “**cláusula de barreira**”, a qual “restringia o direito ao funcionamento parlamentar, o acesso ao horário gratuito de rádio e televisão e a distribuição dos recursos do Fundo Partidário” (*Notícias STF*, 07.12.2006 — 20h29).

Assim, o STF declarou inconstitucionais diversos dispositivos que procuravam condicionar “... o funcionamento parlamentar a determinado desempenho eleitoral, conferindo, aos partidos, diferentes proporções de participação no Fundo Partidário e de tempo disponível para a propaganda partidária (‘direito de antena’), conforme alcançados, ou não, os patamares de desempenho impostos para o funcionamento parlamentar”.

“Entendeu-se que os dispositivos impugnados violam o art. 1.º, V, que prevê como um dos fundamentos da República o pluralismo político; o art. 17, que estabelece ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana; e o art. 58, § 1.º, que assegura, na constituição das Mesas e das comissões permanentes ou temporárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa, todos da CF. Asseverou-se, relativamente ao inciso IV do art.

17 da CF, que a previsão quanto à competência do legislador ordinário para tratar do funcionamento parlamentar não deve ser tomada a ponto de esvaziar-se os princípios constitucionais, notadamente o revelador do pluripartidarismo, e inviabilizar, por completo, esse funcionamento, acabando com as bancadas dos partidos minoritários e impedindo os respectivos deputados de comporem a Mesa Diretiva e as comissões. Considerou-se, ainda, sob o ângulo da razoabilidade, serem inaceitáveis os patamares de desempenho e a forma de rateio concernente à participação no Fundo Partidário e ao tempo disponível para a propaganda partidária adotados pela lei. Por fim, ressaltou-se que, no Estado Democrático de Direito, a nenhuma maioria é dado tirar ou restringir os direitos e liberdades fundamentais da minoria, tais como a liberdade de se expressar, de se organizar, de denunciar, de discordar e de se fazer representar nas decisões que influem nos destinos da sociedade como um todo, enfim, de participar plenamente da vida pública” ([ADI 1.351/DF](#) e [ADI 1.354/DF](#), Rel. Min. Marco Aurélio, 07.12.2006 — *Inf. 451/STF*).

Avançando à regra que assegura o denominado *direito de antena*, o STF, no julgamento das [ADIs 4.430](#) e [4.795](#), entendeu estar garantida, mesmo às legendas criadas após as últimas eleições, a possibilidade de participar do rateio de 2/3 do tempo da propaganda, que é dividido entre os partidos com representação na Câmara dos Deputados, nos termos do art. 47, § 2.º, II, da Lei n. 9.504/97. Ainda, tendo em vista a regra do art. 17, § 3.º, da CF/88, determinou que o outro terço do tempo deveria ser rateado entre **todos os partidos**, mesmo que não tenham representação na Câmara dos Deputados (*Inf. 672/STF*).[4](#)

■ 18.4. O PRINCÍPIO DA VERTICALIZAÇÃO DAS COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS E A EC N. 52/2006

■ 18.4.1. Primeiro momento — a consagração da regra da verticalização das coligações partidárias pelo TSE

Retomando a regra do art. 17, I, da CF/88, que prevê a observância do preceito do **caráter nacional** dos partidos políticos, muita discussão surgiu em torno da decisão do TSE que determinou a **verticalização das coligações partidárias** para as eleições de 2002 (cf. art. 4.º, § 1.º, da Instrução Normativa n. 55/TSE, de 26.02.2002 — Res. n. 20.993/2002 e **Res. n. 21.002/2002**, tendo em vista a **Consulta n. 715/021**).⁵

Isso porque, ao interpretar o art. 6.º, *caput*, da Lei n. 9.504/97,⁶ o TSE entendeu que a circunscrição maior (**federal** — candidatos à Presidência da República) engloba a menor (**estadual** — Governador, Senadores, Deputados Federais e Estaduais).

De maneira bastante interessante, em seu voto à Consulta n. 715, a Ministra Ellen Gracie, retomando o entendimento firmado na Consulta n. 382-TSE (Rel. Min. Néri da Silveira) e na Consulta n. 738, que consagrou o princípio da **simetria entre candidaturas majoritárias e proporcionais**, com propriedade, asseverou: “... o âmbito de validade da restrição a que corresponde a cláusula — **dentro da mesma circunscrição** — deve ser entendido como o espaço maior, aquele em que se dá a eleição nacional. As coligações que neste patamar se formarem condicionam e orientam as que forem propostas para o âmbito dos estados-membros”. Qualquer outro entendimento, completa, levaria “... a situações de **bicefalia**, ou, se preferirem, de **esquizofrenia partidária**, no nível estadual. Ou então, pior ainda, levariam a indesejáveis **dissidências regionais em relação aos partidos**, os quais, na forma da Constituição Federal, têm caráter nacional (art. 17, I)”.

A regra do caráter nacional dos partidos políticos, conclui, “... sinaliza no sentido da **coerência partidária** e no da **consistência ideológica das agremiações e das alianças** que se venham a formar, com inegável **aperfeiçoamento do sistema político-partidário**”.

Assim, os partidos políticos, para a coligação nas eleições estaduais, deverão obedecer, tendo em vista a também denominada “**teoria dos conjuntos**” (circunscrição maior absorvendo a menor), aos mesmos termos dos acordos nacionais fixados para as eleições presidenciais.

Apenas se alerta que referida regra da verticalização **não** se aplica às eleições municipais, já que, nessas hipóteses, não há simultaneidade de circunscrições. Isso porque a eleição municipal ocorre em momento diverso dos demais pleitos, caracterizando-se no jargão eleitoral, conforme lembrou o Ministro Nelson Jobim, uma “eleição solteira” (voto em CTA n. 715/2002).

Alerta-se, ainda, que, em segunda apreciação sobre o assunto, ao responder a diversas consultas (*vide*, v. g., as de ns. 745/DF, 758/DF, 759/DF, 760/DF, 762/DF e 766/DF), o Ministro relator, Fernando Neves, refletindo o entendimento do TSE, **flexibilizou** as alianças para os partidos que não apresentem candidatos à presidência: “Consulta — Partido que não lançou candidato à eleição presidencial, isoladamente ou em coligação — Coligações — Possibilidades. 1. Partido político que não esteja disputando a eleição presidencial, isoladamente ou em coligação, pode, em Estados diversos e no Distrito Federal, celebrar coligações para as eleições majoritárias estaduais, com diferentes partidos que estejam disputando a eleição presidencial, com diferentes candidatos. 2. A coligação formada para disputar a eleição presidencial pode ser dividida e os partidos que a componham disputar, em grupos ou isoladamente, a eleição para governador. 3. Os partidos ou coligações não estão obrigados a lançar candidatos a todos os cargos em disputa” (CTA n. 762, Res. n. 21.048/TSE).

■ 18.4.2. Ataques à regra da verticalização das coligações partidárias fixada pelo TSE

A regra da **verticalização das coligações partidárias** (circunscrição federal em relação à estadual e distrital) imposta pelo TSE sofreu, contudo, três importantes “ataques”:

- foi questionada no STF (ADIs 2.628-3, de 14.03.2002; e 2.626-7, de 12.03.2002, Rel. Min. Sydney Sanches);
- ensejou a elaboração de projeto de decreto legislativo do CN objetivando suspender a aludida decisão do TSE que determinou a

vinculação das coligações partidárias federais e estaduais;

■ motivou a elaboração da PEC n. 4/02-SF (PEC n. 548/02-CD), pretendendo alterar o § 1.º do art. 17.

O STF, por maioria, **não conheceu das duas ADIs**, entendendo “... que o dispositivo impugnado limitou-se a dar interpretação ao art. 6.º da Lei n. 9.504/97, caracterizando-se, portanto, como ato normativo secundário de natureza interpretativa, de modo que os eventuais excessos do poder regulamentar da Resolução em face da Lei n. 9.504/97 não revelariam inconstitucionalidade, mas sim eventual ilegalidade frente à Lei ordinária regulamentada, sendo indireta, ou reflexa, a alegada ofensa à CF, cuja análise é incabível em sede de controle abstrato de normas” (*Inf. 264/STF*, **15 a 19.04.2002**).

O projeto de decreto legislativo, após ser considerado inconstitucional pelo Presidente da CD, restou prejudicado por 263 votos a 152.

A **PEC n. 4/2002** foi aprovada em segundo turno no SF. Encaminhada para a CD, recebeu o n. **548/2002**, tendo sido, em 13.02.2004, apresentado o Parecer da CCJR do relator, Deputado José Ivo Sartori, pela **admissibilidade**. Em **08.02.2006**, o Plenário da CD aprovou, em segundo turno, a referida PEC, **acabando com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias em campanhas eleitorais**. A PEC só foi promulgada como **EC n. 52** em **08.03.2006**, portanto, um mês após a sua aprovação, com a seguinte redação conferida ao art. 17, § 1.º, da CF/88:

“Art. 17. (...) § 1.º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, **sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal**, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”.

O art. 2.º da EC n. 52/2006 determinou a sua aplicação às eleições que ocorreram no ano de 2002, já finda! Sem dúvida, o objetivo dessa remissão era fazer com que a nova regra, supostamente direcionada para as eleições de 2002,

já se aplicasse para as eleições de 2006.

A demora em promulgar a referida PEC, já aprovada, certamente deveu-se ao temor da regra fixada no art. 16 da CF/88 e abaixo comentada.

Isso porque se vislumbrava a possibilidade de o TSE mudar o entendimento firmado em 2002, revendo a Resolução TSE n. 21.002/02, em razão de nova consulta formulada por Ronaldo Nóbrega Medeiros, Secretário-Geral da Comissão Executiva Nacional do Partido Social Liberal (**CTA n. 1.185/2005 e Res. n. 22.161**).

Entretanto, em **03.03.2006**, o TSE, por 5 x 2, manteve o entendimento de 2002, reforçando a regra da **verticalização das coligações partidárias** para as eleições de 2006.

Sem outra alternativa, as Mesas da CD e do SF promulgaram, como visto, em **08.03.2006**, a **EC n. 52**.

Primeira questão: a nova regra é constitucional?

Em nosso entender, a **EC n. 52/2006** viola a cláusula pétrea do **direito e garantia individual** de terem os partidos políticos **caráter nacional, coerência partidária e consistência ideológica**, bem como o **princípio da segurança jurídica**, já que inova violando a regra do devido processo eleitoral.

Segunda questão: sendo considerada constitucional, a nova regra poderia ter sido aplicada às eleições de 2006?

Entendemos que **não**, pois, ao ser promulgada e publicada, a **EC n. 52/2006** suplantou a Res. n. 21.002/2002, afastando, expressamente, a regra da verticalização.

Trata-se, portanto, sem dúvida, de **lei nova que altera o processo eleitoral**. Assim, nos termos do **art. 16 da CF/88**, a nova regra, que entrou em vigor na data de sua publicação (**09.03.2006**), não poderia ser aplicada à eleição que ocorresse até um ano da data de sua vigência (**09.03.2007**).

O art. 16 da CF/88, reforçado pela regra que lhe foi conferida pela **EC n. 4/94**, consagra, de vez e claramente, o **princípio da anualidade**, caracterizador da segurança jurídica do processo eleitoral, evitando, assim, surpresas, tanto para o cidadão e eleitor como para o interessado em se candidatar.

Sepúlveda Pertence, ao comentar o art. 16 da CF/88, observou tratar-se de “... inovação salutar inspirada na preocupação de qualificada estabilidade e lealdade do devido processo eleitoral: nele a preocupação é especialmente de **evitar que se mudem as regras do jogo que já começou**, como era frequente, com os sucessivos ‘casuísmos’, no regime autoritário decaído” (voto em Consulta n. 715/TSE).

Celso de Mello, em igual sentido, em outro julgado, destacou a importância da regra do art. 16 da CF/88, mesmo antes de sua nova redação fortalecida pela EC n. 4/94: “... A norma inscrita no art. 16 da Carta Federal, consubstanciadora do princípio da anterioridade da lei eleitoral, foi enunciada pelo constituinte com o declarado propósito de **impedir a deformação do processo eleitoral mediante alterações casuisticamente nele introduzidas**, aptas a romperem a igualdade de participação dos que nele atuem como protagonistas principais: as agremiações partidárias e os próprios candidatos...” (STF, Pleno, ADI 353-MC/DF — DJ 1, de 12.02.1993, p. 1450).

Deve-se ressaltar que, no caso de lei definindo regras para a hipótese da **eleição indireta no regime de dupla vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República** (art. 81, § 1.º), não há falar em necessidade de observar o art. 16, já que, conforme interpretou o STF no julgamento das ADIs 4.298 e 4.309 (07.10.2009), não se cuida de lei *materialmente eleitoral*, mas de lei que trata de “... **matéria político-administrativa** que demandaria típica decisão do **poder geral de autogoverno**, inerente à **autonomia política dos entes federados**” (Inf. 562/STF — cf. item 10.4.6.3).

■ **18.4.3. Ataques à regra da EC n. 52/2006, que expressamente acabou com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Mantida a verticalização para as eleições de 2006 (princípio da anualidade — art. 16 da CF). A EC n. 52/2006 entrou em vigor na data de sua publicação, mas somente poderá ser aplicada às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência**

Conforme visto, o objetivo explícito da EC n. 52/2006 foi sepultar, de vez, a

regra da obrigatoriedade das coligações partidárias, já que, ao modificar o art. 17, § 1.º, da CF/88, assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, **sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal**, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Buscando afastar essa nova prescrição trazida pela EC n. 52/2006, três medidas foram tomadas por aqueles que eram favoráveis à preservação do princípio da verticalização das coligações partidárias:

■ **MS 25.811** — ajuizado em 27.01.2006 pelo Deputado Federal Miro Teixeira, ainda durante a tramitação do processo legislativo, buscava suspender a votação da referida PEC n. 548-B/2002, que objetivava o fim da verticalização das coligações políticas e viria a ser transformada na EC n. 52/2006.

O Ministro Cezar Peluso julgou **prejudicado** o referido MS, uma vez que veio a ser apreciado somente quando a PEC já havia se transformado em EC n. 52/2006. Consoante estudado no *item 6.4.1.3* deste trabalho, o controle prévio ou preventivo realizado pelo parlamentar para assegurar o *devido processo legislativo* de formação da lei visa, exclusivamente, “trancar” o andamento do processo legislativo. Quando o projeto se transforma em espécie normativa, perde utilidade o mandado de segurança, devendo a norma produzida ser atacada mediante controle difuso ou concentrado, posterior e repressivo.

Outro ponto a justificar o não conhecimento do MS foi o fato de o STF ter mantido a regra da verticalização no julgamento da ADI 3.685, como se verá a seguir, só que, dando interpretação conforme o art. 16 da CF/88, tendo em vista o princípio da anualidade.

■ **ADI 3.685** — ajuizada em **09.03.2006**, pelo Conselho Federal da OAB, objetivava reconhecer a inconstitucionalidade da nova regra por violação ao art. 16 da CF/88;

■ **ADI 3.686** — ajuizada em **09.03.2006**, pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), também pretendia a declaração de inconstitucionalidade da EC n. 52/2006, aduzindo diversos argumentos.⁷

O STF, em um primeiro momento, tendo em vista a conexão da ADI 3.686 com a de n. 3.685, determinou o julgamento conjunto das ações.

Em 15.03.2006, porém, a Ministra Relatora, Ellen Gracie, entendeu que, em relação à ação ajuizada pela CONAMP, não se reconhecia a necessária **pertinência temática** entre os fins institucionais da Associação de Classe do MP e o alcance da norma impugnada, qual seja, a EC n. 52/2006. Assim, **negou seguimento à ADI 3.686**.⁸

Restou o julgamento da **ADI 3.685**, ajuizada pela OAB, que restringia o pedido à violação do art. 16 da CF/88.

Em nosso entender, a EC n. 52/2006 deveria ter sido reconhecida como totalmente inconstitucional, já que violou a cláusula pétrea do direito e garantia individual, do **caráter nacional** dos partidos políticos e da segurança jurídica — art. 60, § 4.º, IV, c/c os arts. 17, I, 16; e 5.º, *caput*, todos da CF/88.

Contudo, por 9 x 2, tendo em conta o **princípio da anualidade**, previsto expressamente no art. 16 da CF/88, e buscando evitar o **atalhamento da Constituição**,⁹ o STF reconheceu que **a nova regra não poderia ser aplicada às eleições de 2006**.

Nesse sentido, reconheceu que “a emenda violou a Constituição Federal e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘aplicando-se às eleições que ocorrerão no ano de 2002’, contida no artigo 2.º da emenda atacada. A ministra também deu interpretação conforme à Constituição à parte remanescente da emenda, no sentido de que as novas regras sejam aplicadas somente após um ano da data de sua vigência” (cf. o resumo dos votos em *Notícias STF*, 22.03.2006 — 20h46). Pedimos vênias para transcrever a ementa do acórdão da ADI 3.685:

“A inovação trazida pela EC 52/06 conferiu *status* constitucional à matéria até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal,

provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral (ADI n. 354, Rel. Min. Octavio Gallotti, *DJ* 12.02.1993). Enquanto o art. 150, III, *b*, da CF encerra garantia individual do contribuinte (ADI n. 939, Rel. Min. Sydney Sanches, *DJ* 18.03.1994), **o art. 16 representa garantia individual do cidadão-eleitor**, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e ‘a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral’ (ADI n. 3.345, Rel. Min. Celso de Mello). Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos arts. 5.º, § 2.º, e 60, § 4.º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5.º, *caput*) e do devido processo legal (CF, art. 5.º, LIV). A modificação no texto do art. 16 pela EC 4/93 em nada alterou seu conteúdo principiológico fundamental. Tratou-se de mero aperfeiçoamento técnico levado a efeito para facilitar a regulamentação do processo eleitoral. Pedido que se **julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1.º da EC 52/06 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência**” (ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22.03.2006, *DJ*, de 10.08.2006 — grifamos. Sobre o assunto, cf., ainda, *Inf. 420/STF*).

■ 18.5. FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Muito se discutiu sobre a questão da **fidelidade partidária**. O STF, em 03 e 04.10.2007, julgando os **MS 26.602**, **26.603** e **26.604**, resolveu a matéria em relação ao **sistema proporcional** (eleição de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores) e entendeu que a fidelidade partidária é princípio

constitucional que deve ser respeitado pelos candidatos eleitos.

Assim, teoricamente, aquele que mudar de partido (**transferência de legenda**) sem motivo justificado **perderá o cargo eletivo**.

Isso porque reconheceu o STF o caráter eminentemente partidário do sistema proporcional e as inter-relações entre o eleitor, o partido político e o representante eleito.

Mudar de partido caracteriza desvio ético-político e gera desequilíbrio no Parlamento. É fraude contra a vontade do povo.

No caso dos referidos MS, deixamos claro novamente, o STF os apreciou somente em relação aos mandatos eletivos sob as regras do **sistema proporcional** (deputados e vereadores). Nesse sentido, seguindo o julgamento pelo TSE na **CTA n. 1.398**, o STF fixou a data de **27.03.2007** como o marco a partir do qual qualquer eleito (pelo sistema proporcional) que mudar de partido, sem justo motivo, estará violando as regras de fidelidade partidária.

Em momento seguinte, o **TSE**, no julgamento da **CTA n. 1.407**, entendeu que também para os cargos eletivos pelo sistema majoritário incidiria a regra de perda do cargo para o eleito infiel (salvo, claro, justa causa). Para esses cargos, a data-marco foi **16.10.2007**, ou seja, qualquer eleito pelo sistema majoritário (Chefes de Executivo e Senadores) que mudasse de partido a partir de referida data perderia o cargo, salvo justo motivo.

Esse entendimento foi confirmado pela Corte Eleitoral na **Res. n. 22.610/2007** que também disciplinou o processo de perda de cargo eletivo, bem como o de justificação de desfiliação partidária.

O STF entendeu competente a Justiça Eleitoral para dispor sobre o tema da perda de mandato, tendo em vista o seu **poder regulamentar** (ADI 3.999 e ADI 4.086, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12.11.2008, *DJE* de 17.04.2009).

Contudo, em momento seguinte, outro ponto diverso foi trazido na **ADI 5.081**, proposta pelo PGR: a Justiça Eleitoral teria legitimidade para estender a regra da fidelidade partidária aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário (Chefes do Executivo e Senadores da República)?

NÃO.

Em **27.05.2015**, a Corte, por unanimidade, fixou a seguinte tese: “a perda do mandato em razão da mudança de partido **não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário**, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor”.

De acordo com o item 3 da ementa do voto do Min. Barroso, “o sistema majoritário, adotado para a eleição de Presidente, Governador, Prefeito e Senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. **As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular** (CF, art. 1.º, par. ún., e art. 14, *caput*)”. Assim, **a perda de mandato por troca de partido não se aplica ao sistema majoritário**.

O processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, continua estabelecido na **Res. n. 22.610**, de 25.10.2007 (*DJ* de 30.10.2007), do TSE, com a redação dada pela **Res. n. 22.733/2008**, também do TSE, mas sem a sua aplicação para os candidatos eleitos pelo sistema majoritário.

A ação tramitará perante o TSE para pedidos relativos a mandato federal e, nos demais casos, perante o TRE do respectivo Estado.

Segundo a Resolução, considera-se **justa causa**:

- incorporação ou fusão do partido;
- criação de novo partido;
- mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
- grave discriminação pessoal.

O tema da fidelidade partidária é extremamente importante tendo sido questionado, por parte da doutrina e de Parlamentares, no sentido de que o TSE, ao legislar, teria usurpado competência legislativa e, acima de tudo, criado mais uma hipótese de perda de mandato não expressa no art. 55 da CF.

Apesar da excelência dos argumentos, havíamos sugerido uma interpretação no sentido de justificar o procedimento fixado na referida resolução, qual seja, o

art. 55, V, que estabelece a perda do mandato “quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição”.

Não há regra expressa, mas a ideia de fidelidade decorre de uma análise sistemática da Constituição.

Finalmente, em complemento ao tema, cabe observar decisão bastante complexa proferida pelo STF em relação à transferência ou não do direito de sucessão ao novo partido em razão de mudança por justa causa, na hipótese de superveniente vacância.

O caso concreto envolvia a mudança de partido pelo então Deputado Federal *Clodovil Hernandez*, famoso estilista, tendo sido reconhecida a justa causa pelo TSE.

Com a morte de Clodovil, surgiu a questão de saber se o suplente deveria ser do partido pelo qual ele foi eleito ou do novo partido que o recebeu em virtude da mudança por justa causa.

A questão foi resolvida pelo Pleno no julgamento do **MS 27.938**, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. TROCA DE PARTIDO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. POSTERIOR VACÂNCIA DO CARGO. MORTE DO PARLAMENTAR. SUCESSÃO. LEGITIMIDADE. O reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. **Contudo, ela não transfere ao novo partido o direito de sucessão à vaga.** Segurança denegada” (MS 27.938, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 11.03.2010, Plenário, *DJE* de 30.04.2010).

Conforme anotou o Min. Joaquim Barbosa, “como a troca de partidos não é submetida ao crivo do eleitor, o **novo vínculo** de fidelidade partidária **não recebe legitimidade democrática** inequívoca para a sua perpetuação e, assim, **não há a transferência da vaga à nova sigla**”.

■ 18.6. A VAGA DECORRENTE DO LICENCIAMENTO DE TITULARES DE MANDATO PARLAMENTAR DEVE SER OCUPADA PELOS SUPLENTE

DAS COLIGAÇÕES OU DOS PARTIDOS?

O STF, no julgamento dos **MS 30.260** e **30.272**, em 27.04.2011, por 10 x 1, entendeu que a vaga decorrente do licenciamento de titulares de mandato parlamentar, no caso para assumir cargos de secretarias de Estado, deve ser ocupada pelos **suplentes das coligações**, e não dos partidos.

Pode-se afirmar, então, que, se houve formação de coligação, o que é opcional e encontra fundamento na Constituição (art. 17, § 1.º), a vaga de suplência pertence a esta, e não ao partido político.

A **suplência** no caso das coligações também não se confunde com a **infidelidade**, já que esta se caracteriza como **deslealdade ao partido político** e **fraude ao eleitor**, conforme visto, sendo que, no entanto, o candidato eleito por coligação acaba se beneficiando da referida aliança.

Nesse sentido, como definido pelo STF, o que pedimos vênha para transcrever em razão da clareza, ¹⁰ “as **coligações** são conformações políticas decorrentes da aliança partidária formalizada entre dois ou mais partidos políticos para concorrerem, de forma unitária, às eleições proporcionais ou majoritárias. Distinguem-se dos partidos políticos que as compõem e a eles se sobrepõem, temporariamente, adquirindo capacidade jurídica para representá-los”.

“A figura jurídica derivada dessa coalizão transitória não se exaure no dia do pleito ou, menos ainda, apaga os vestígios de sua existência quando esgotada a finalidade que motivou a convergência de vetores políticos: eleger candidatos. Seus efeitos projetam-se na definição da ordem para ocupação dos cargos e para o exercício dos mandatos conquistados.”

“A **coligação assume** perante os demais partidos e coligações os órgãos da Justiça Eleitoral e, também, os eleitores, **natureza de superpartido**; ela formaliza sua composição, registra seus candidatos, apresenta-se nas peças publicitárias e nos horários eleitorais e, a partir dos votos, forma quociente próprio, que não pode ser assumido isoladamente pelos partidos que a compunham nem pode ser por eles apropriado.”

“O **quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação**, contemplando seus candidatos mais

votados, independentemente dos partidos aos quais são filiados. Regra que deve ser mantida para a convocação dos suplentes, pois eles, como os eleitos, formam lista única de votações nominais que, em ordem decrescente, representa a vontade do eleitorado.”

“A sistemática estabelecida no ordenamento jurídico eleitoral para o preenchimento dos cargos disputados no sistema de eleições proporcionais é declarada no momento da diplomação, quando são ordenados os candidatos eleitos e a ordem de sucessão pelos candidatos suplentes. **A mudança dessa ordem atenta contra o ato jurídico perfeito e desvirtua o sentido e a razão de ser das coligações.**”

“Ao se coligarem, os partidos políticos aquiescem com a possibilidade de distribuição e rodízio no exercício do poder buscado em conjunto no processo eleitoral.”

■ 18.7. FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS — ADI 4.650

O Conselho Federal da OAB ajuizou em 05.09.2011 a **ADI 4.650**, questionando as regras sobre doações privadas para campanhas eleitorais e partidos políticos e, assim, atacando dispositivos da *Lei das Eleições* (Lei n. 9.504/97) e *Lei dos Partidos Políticos* (Lei n. 9.096/95), que regulam as contribuições de pessoas jurídicas e pessoas físicas para as campanhas eleitorais.

Critica-se o uso do poder econômico, objetivando não ser admitido o financiamento por pessoas jurídicas, nem mesmo o seu atrelamento ao rendimento das pessoas físicas.

Pela regra atual, as **pessoas jurídicas** podem doar até **2%** do seu faturamento bruto do ano anterior à eleição (art. 81, § 1.º, da Lei n. 9.504/97), o que geraria a influência do poder econômico sobre o poder político.

Em seu voto, destaca o Min. Fux: “em 2002 foram gastos no país R\$ 798 milhões em campanhas eleitorais, e em 2012, o valor foi de R\$ 4,5 bilhões — um crescimento de 471%. O gasto *per capita* do Brasil com campanhas supera o de países como França, Alemanha e Reino Unido, e como proporção do PIB,

é maior do que os EUA. Em 2010, o valor médio gasto por um deputado federal eleito no Brasil chegou a R\$ 1,1 milhão, e um senador, R\$ 4,5 milhões. Esses recursos, por sua vez, são doados por um universo pequeno de empresas — os dez maiores doadores correspondem a 22% do total arrecadado” (*Notícias STF*, 11.12.2013).

E afirma: “**o exercício de direitos políticos é incompatível com as contribuições políticas de pessoas jurídicas**. Uma empresa pode até defender causas políticas, como direitos humanos, mas há uma grande distância para isso justificar sua participação no processo político, investindo valores vultosos em campanhas”, contrariando, assim, a essência do regime democrático (*idem*).

Por sua vez, as **pessoas físicas** podem fazer doações limitadas a **10%** de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Para o Min. Fux, a **doação balizada pela renda desequilibra o processo eleitoral** (art. 23, § 1.º, I, da Lei n. 9.504/97).

Ainda, o Min. Fux, relator, em seu voto, declarou inconstitucional a limitação, no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido (art. 23, § 1.º, II, da Lei n. 9.504/97).

Conforme noticiado, “nesses dois pontos, o Ministro decidiu modular os efeitos de sua decisão, determinando o prazo de 24 meses para que o Congresso Nacional crie novo marco normativo sobre o assunto. Para tal, o Ministro traçou como diretriz a criação de um limite para doação por pessoa natural que seja uniforme, em patamares que **não comprometam a igualdade de oportunidades entre os candidatos**, o mesmo se aplicando para as regras relativas a recursos próprios dos candidatos. Caso o Congresso se abstenha de criar tal regra, o ministro estipulou o prazo de 18 meses para que o TSE regule provisoriamente o tema, até que nova lei seja aprovada” (*Notícias STF*, 11.12.2013).

Até o fechamento desta edição, 4 Ministros acompanhavam o Min. Fux para declarar inconstitucional o atual modelo de financiamento das campanhas eleitorais por *pessoas jurídicas*, bem como em relação às *pessoas físicas*, não mais admitindo a sistemática que prestigia o poder econômico, prescrevendo,

por outro lado, critérios mais objetivos e isonômicos. O Min. Marco Aurélio julgou parcialmente procedente a ADI apenas para nulificar o modelo de financiamento por pessoas jurídicas, não condenando a possibilidade de doação por pessoa física.

Em **02.04.2014** houve pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. Sem dúvida essa sinalização de 6 Ministros condenando o atual mecanismo de financiamento estimulará o Congresso Nacional a sair de sua inércia e aprovar a necessária **reforma política** que, sem dúvida, terá que considerar a conveniência ou não do financiamento público das campanhas. O que não dá mais para se admitir é o atual modelo que, inegavelmente, **deturpa a democracia** (*matéria pendente*).

■ 18.8. QUESTÕES

1. (MP/81.º/2.ª Prova) Os partidos políticos:

- a) são pessoas jurídicas de direito público interno; devem ter caráter nacional; seu patrimônio, bens e serviços, bem como os de suas fundações, não sofrem, por força de vedação constitucional, a instituição de impostos;
- b) são pessoas jurídicas de direito público interno; devem ter caráter nacional; não podem subordinar-se a governo estrangeiro;
- c) são pessoas jurídicas de direito privado; acham-se proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, mas não têm direito à imunidade tributária;
- d) são pessoas jurídicas de direito privado; devem ter caráter nacional; desfrutam de imunidade tributária; sujeitam-se à proibição de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
- e) são pessoas jurídicas de direito público; não podem subordinar-se a entidade ou governo estrangeiros, mas deles podem receber recursos financeiros, sendo-lhes também assegurada imunidade tributária.

2. (MP/Minas Gerais — XLIV 2004) Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Partidos políticos que se propõem a disputar apenas eleições estaduais registram seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral da respectiva unidade da Federação.
- b) O partido político é associação de pessoas que, após o registro de seus estatutos no

órgão eleitoral competente, adquire natureza de pessoa jurídica de direito público interno.

- c) É livre a criação de partidos políticos, mas a C.F. vigente, para preservação do regime democrático, do pluripartidarismo e dos direitos fundamentais da pessoa humana, prevê controle ideológico ou qualitativo sobre as citadas agremiações.
- d) Lei que alterar processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação sendo aplicável às eleições que ocorram a partir da sua vigência.
- e) Segundo a vigente C.F., fidelidade e disciplina partidárias são matérias que devem ser regulamentadas por lei, cabendo aos partidos adequar seus estatutos às normas legais.

3. (juiz/TRF 5RG/2007) Acerca dos partidos políticos, julgue o seguinte item.

Mantidas as atuais regras eleitorais, nas eleições de 2010, os partidos políticos não estarão vinculados, no plano estadual, ao princípio da simetria de coligações partidárias que se realizem para a eleição presidencial.

4. (DP/SE/2005) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A personalidade jurídica dos partidos políticos é adquirida na forma da lei civil.

5. (DP/TO/CESPE/UnB/2008) Considerando o que dispõem as normas a respeito dos direitos políticos e partidos políticos constantes da Constituição Federal, julgue o seguinte item.

Apesar de terem organização e caráter nacional, os partidos políticos, no Brasil não estão obrigados à vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

6. (TRF 5/CESPE/UnB/2009) Com relação aos partidos políticos, ao alistamento, à eleição e aos direitos políticos, assinale a opção correta.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

7. (Exame de Ordem Unificado.2 — set./2009 — CESPE/UnB/2009) Assinale a opção correta a respeito dos partidos políticos:

- a) a CF consagra o princípio da liberdade partidária de modo ilimitado e irrestrito, não admitindo condicionantes para a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos.

- b) os partidos políticos somente adquirem personalidade jurídica após duplo registro: no registro civil das pessoas jurídicas e no tribunal regional eleitoral do estado em que estão sediados.
- c) como sujeitos de direitos, os partidos políticos têm legitimidade para atuar em juízo, e, se tiverem representação no Congresso Nacional, podem ajuizar mandado de segurança coletivo.
- d) somente os partidos com representação no Congresso Nacional podem usufruir dos recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

8. (Agente Administrativo — MMA — CESPE/UnB/2009) A respeito do direito constitucional, julgue o item que se segue:

Para que um partido político tenha representação no Congresso Nacional, é suficiente que o partido tenha um só parlamentar em qualquer uma das Casas do Congresso.

9. (Técnico Judiciário — TRE-CE — Área Administrativa — FCC/2012) Determinado partido político deseja se utilizar de organização paramilitar no combate ao nepotismo e à corrupção, cuja utilização, segundo a Constituição Federal, é:

- a) lícita, mediante prévia consulta popular através de plebiscito.
- b) lícita, mediante prévio registro no Superior Tribunal Eleitoral.
- c) lícita, mediante prévia autorização do Senado Federal.
- d) vedada.
- e) lícita, mediante prévia autorização das Forças Armadas.

10. (Analista Judiciário/TSE — Área Administrativa — CONSULPLAN/2012) Quanto aos partidos políticos, é correto afirmar que:

- a) o registro de seus estatutos no TSE somente ocorrerá após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil.
- b) têm direito a recursos do fundo partidário e acesso ao rádio e televisão, este mediante pagamento de uma taxa de utilização.
- c) em virtude da autonomia de que desfrutam, é possível que recebam recursos financeiros de governos estrangeiros.
- d) devem ter caráter nacional, o que obriga à vinculação das candidaturas em âmbito federal.

11. (Analista Ministerial — MP/PE — FCC/2012) O partido político URTJ, com

autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, deverá, segundo o inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, prestar contas:

- a) ao Tribunal de Contas da União.
- b) à Justiça Eleitoral.
- c) ao Congresso Nacional.
- d) ao Conselho Nacional de Justiça.
- e) ao Supremo Tribunal Federal.

12. (Analista de Procuradoria — PGE-BA — Área de Apoio Calculista — FCC/2013) Ao enunciar a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a Constituição Federal determina expressamente que o exercício desse direito deve resguardar determinados bens ou valores constitucionais. Encontram-se, entre eles:

- a) o pluripartidarismo, a soberania nacional e a separação dos poderes.
- b) a forma federativa de Estado, os direitos fundamentais da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa.
- c) o pluralismo político, a forma federativa de Estado e a redução das desigualdades regionais e sociais.
- d) a soberania nacional, os direitos fundamentais da pessoa humana e a forma federativa de Estado.
- e) o pluripartidarismo, a soberania nacional e o regime democrático.

13. (Exame de Ordem Unificado-X — 1.ª Fase — FGV/2013) Apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e do vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta:

- a) Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro.
- b) Devem prestar as contas partidárias perante Conselho Especial.
- c) Podem ter caráter regional, representando pelo menos duas regiões.
- d) Têm acesso gratuito ao rádio e à televisão nos limites legais.

14. (Promotor de Justiça — MP-SC) Analise o enunciado da questão abaixo e

assinale “certo” ou “errado”:

Pela disciplina constitucional do Brasil, os partidos políticos somente podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras se, regularmente constituídos e sem pendências com a Justiça Eleitoral, obtiverem aprovação do correlato plano de investimentos junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

■ GABARITO ■

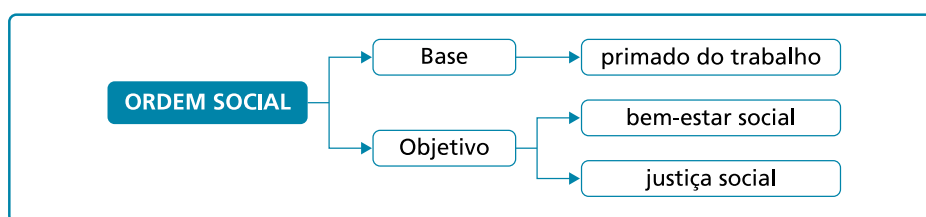
1. “d”. Art. 17, c/c o art. 150, VI, “c”, da CF/88.
2. “c”. No tocante à alternativa “a”, o registro dos estatutos é no TSE (art. 17, § 2.º). A letra “b” está errada, já que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. A letra “d” está errada, pois, consagrando o princípio da anualidade, o art. 16 da CF/88 estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral, de fato, entrará em vigor na data de sua publicação. Contudo, só poderá ser aplicada na eleição que ocorrer a partir de um ano da data de sua vigência. Por fim, a letra “e” está errada, já que, nos termos do art. 17, § 1.º, os estatutos é que estabelecerão normas de disciplina e fidelidade partidária.
3. “certo”.
4. “certo”.
5. “certo”. De fato, apesar da regra do art. 17, I (caráter nacional), a EC n. 52/2006, ao modificar o art. 17, § 1.º, admitiu o fim da verticalização das coligações partidárias.
6. “errado”, pois, conforme visto na parte teórica, a constituição dos partidos políticos consolida-se na forma da lei civil, perante o Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente (na Capital Federal, Brasília — art. 8.º da Lei n. 9.096/95) e, posteriormente, já tendo adquirido a personalidade jurídica, formaliza-se por meio do registro de seus estatutos perante o TSE.
7. “c”, nos termos do art. 5.º, LXX, “a”, da CF/88.
8. “certo”.
9. “d”, nos termos do art. 17, § 4.º, da CF/88.

10. “a”, nos termos do art. 17, § 2.º, da CF/88.
11. “b”.
12. “e”, de acordo com o art. 17, <i>caput</i> .
13. “d”, de acordo com o art. 17, § 3.º. A <i>letra “a”</i> está errada, por violar o art. 17, II (proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes). A <i>letra “b”</i> está errada, porque a prestação de contas se dá em relação à Justiça Eleitoral (art. 17, III). A <i>letra “c”</i> viola a regra segundo a qual os partidos políticos terão, necessariamente, nos termos do art. 17, I, caráter nacional.
14. “errado”, por violar o art. 17, II, que proíbe o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.

ORDEM SOCIAL

■ 19.1. ASPECTOS GERAIS

■ 19.1.1. Valores da ordem social: base e objetivo



A ideia de **constituição social** está materializada no Título VIII da CF/88, que trata da **ordem social**.

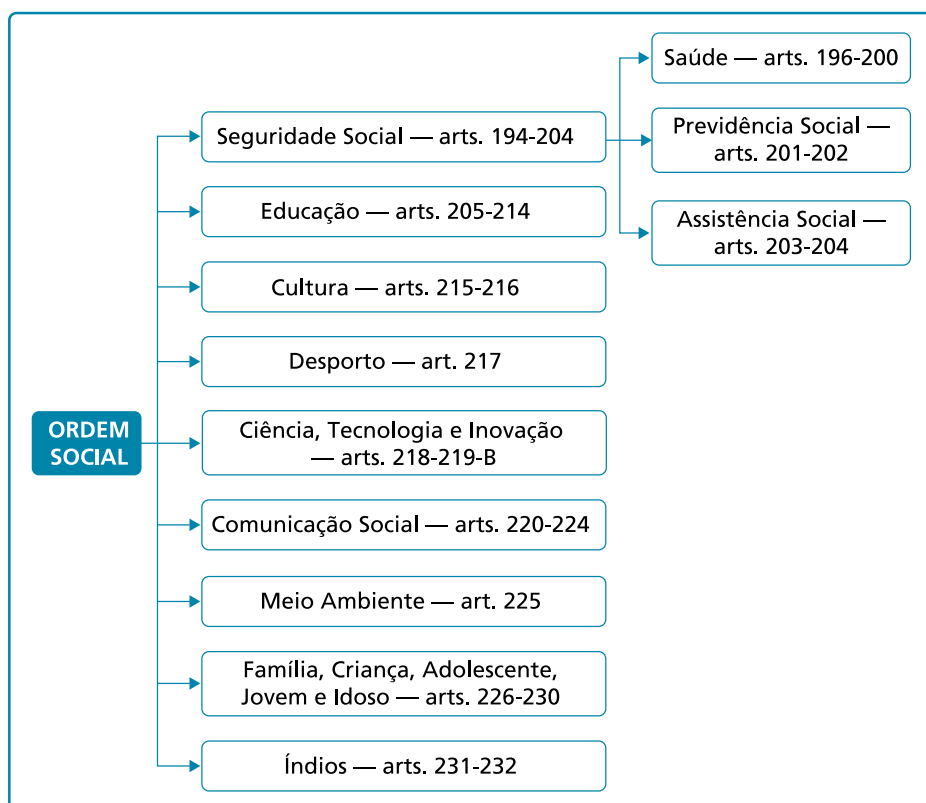
Nos termos do art. 193, a ordem social tem como **base o primado do trabalho** e como **objetivo, o bem-estar** e a **justiça sociais**, estabelecendo perfeita harmonia com a *ordem econômica*, que se funda, também, a teor do art. 170, *caput*, na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa. A ordem econômica tem por fim (objetivo), em igual medida, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Segundo José Afonso da Silva, “ter como *objetivo* o bem-estar e a justiça sociais quer dizer que as relações econômicas e sociais do país, para gerarem o bem-estar, hão de propiciar trabalho e condição de vida, material, espiritual e intelectual, adequada ao trabalhador e sua família, e que a riqueza produzida no país, para gerar justiça social, há de ser equanimemente distribuída”.¹

■ 19.1.2. Conteúdo da ordem social

De acordo com o art. 6.º da CF/88 (ECs ns. 26/2000 e 64/2010), o ser humano apresenta-se como destinatário dos direitos sociais, quais sejam: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.

Nesse contexto, com razão, anota José Afonso da Silva² que, juntamente com o título dos direitos fundamentais, a ordem social forma o **núcleo substancial do regime democrático**, apresentando o seguinte conteúdo, que será desenvolvido ao longo deste capítulo:



De fato, concordamos com o autor ao reconhecer que nem todos os temas englobados pelo título da ordem social apresentam o referido conteúdo típico, por exemplo, *ciência, tecnologia e inovação*, *meio ambiente* e sobretudo *índios*, que serão tratados dentro de um contexto bastante alargado de ordem social, simplesmente pela conveniência didática da sequência apresentada pela

Constituição.

■ 19.2. SEGURIDADE SOCIAL

A **seguridade social** compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social** (art. 194, *caput*), sobressaindo os seus princípios orientadores e as formas de seu financiamento, que passam a ser indicados. [3](#)

■ 19.2.1. Princípios orientadores da organização da seguridade social

Dispõe o art. 194, parágrafo único, que compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- universalidade da cobertura e do atendimento;
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
- seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
- irredutibilidade do valor dos benefícios;
- equidade na forma de participação no custeio;
- diversidade da base de financiamento;
- caráter democrático e descentralizado da administração.

■ 19.2.2. Financiamento da seguridade social

Na dicção do art. 195 da CF/88, a **seguridade social** será **financiada** por **toda a sociedade**, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

■ **do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:** *a)* a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; *b)* a receita ou o faturamento; *c)* o lucro;

■ **do trabalhador e dos demais segurados da previdência social**, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;

■ **sobre a receita de concursos de prognósticos;**

■ **do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.**

Estamos diante de regras de custeio de toda a seguridade social, incluindo, conforme vimos, saúde, previdência e assistência social.

O STF interpretou de maneira ampla a destinação do dever de custeio da seguridade social, e, nesse particular, cumpre distinguir a imunidade prevista no art. 155, § 3.º, da CF/88.

Redação anterior à dada pela EC n. 33/2001: “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do *caput* deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro **tributo** poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”.

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 33/2001: “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do *caput* deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro **imposto** poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”.

Muitos poderiam cogitar que, antes da redação dada pela EC n. 33/2001 ao art. 155, § 3.º, a imunidade estabelecida para as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País, por falar o texto em **tributo**, e não em **imposto**, abarcaria, também, as contribuições para o financiamento da seguridade social.

Todavia, entendeu o STF que não, devendo o referido art. 155, § 3.º,

harmonizar-se com o art. 195, *caput*:

“COFINS. PIS. Distribuidoras de derivados de petróleo, mineradores, distribuidoras de energia elétrica e executoras de serviços de telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal (sessão do dia 1.º-7-99), concluindo o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 205.355 (Ag.Rg); 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso, abrangendo as contribuições representadas pela COFINS, pelo PIS e pelo FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, a serviços de telecomunicações, e a derivados de petróleo, combustíveis e minerais, entendeu que, sendo elas contribuições sociais sobre o faturamento das empresas, destinadas ao financiamento da seguridade social, nos termos do art. 195, *caput*, da Constituição Federal, não lhes é aplicável a imunidade prevista no art. 155, § 3.º, da Lei Maior’ (RE 224.964, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 9-11-99, *DJ*, 04.02.2000). No mesmo sentido: RE 144.971-DF” (RE 230.337, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 1.º.07.1999, *DJ* de 28.06.2002).

Nessa linha, destacamos a **S. 659/STF**: “É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país” (Sessão Plenária de 24.09.2003).

■ 19.2.3. Competência discriminada (lei ordinária) e competência residual (lei complementar)

As formas de custeio previstas no art. 195, I-IV, materializam-se por **lei ordinária** e no exercício da denominada **competência discriminada** da União. Isso porque, conforme entendimento do STF, não se aplica a regra do art. 146, III, “a” (que exige LC para a modalidade **imposto** de tributo), nem a regra do art. 195, § 4.º, que trata de outras fontes de custeio da seguridade social.

Já para a instituição de outras fontes de custeio destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o art. 154, I, e nos termos do art. 195, § 4.º, indispensável será a **lei complementar**. Trata-se da denominada **competência residual** da União. Nesse sentido:

“SEBRAE. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Lei n. 8.029, de 12.04.1990, art. 8.º, § 3.º. Lei n. 8.154, de 28.12.1990. Lei n. 10.668, de 14.05.2003. CF, art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4.º As contribuições do art. 149, CF, contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, CF, isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. **À contribuição social do art. 195, § 4.º, CF, decorrente de ‘outras fontes’, é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União:** CF, art. 154, I, *ex vi* do disposto no art. 195, § 4.º” (RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.2003, DJ de 27.02.2004).

■ 19.2.4. Inconstitucionalidade do art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718/98 (PIS/PASEP e COFINS). EC n. 20/98 — impossibilidade do fenômeno da “constitucionalidade superveniente”

Como se sabe, o art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718/98 ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP ao dar um novo conceito a **faturamento**, diferentemente do que estabelecia a redação original do art. 195, I, da CF/88, tudo como se percebe pelo quadro abaixo.

REDAÇÃO ORIGINAL DADA AO ART. 195, I, DA CF/88: FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CONTRIBUIÇÕES	CONCEITO DE FATURAMENTO DADO PELO ART. 2.º DA LC N. 70/91	AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS/PASEP PELO ART. 3.º, § 1.º, DA LEI N. 9.718/98	REDAÇÃO DADA AO ART. 195, I, DA CF/88 PELA EC N. 20/98: FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CONTRIBUIÇÕES
			I — do empregador,

I — dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;	Art. 2.º A contribuição de que trata o artigo anterior será de 2% e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.	faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. § 1.º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica , sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.	da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro.
--	--	--	---

Assim, o art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718/98, ao ampliar o conceito de faturamento, extrapolou, criando uma figura sem fundamento no original art. 195, I, já que estabelecia uma ideia de receita. Sob esse aspecto, referida lei “nasceu morta”, viciada, sem fundamento na Constituição.

Trata-se de nulidade absoluta, ou seja, vício congênito, que não pode ser convalidado. Dessa forma, mesmo com o advento da EC n. 20/98 (*DOU* de 16.12.1998), posterior à Lei n. 9.718/98 (*DOU* de 28.11.1998), que passaria a dar sustentáculo ao novo conceito de faturamento, não se pode aceitar a correção do vício de inconstitucionalidade, uma vez que, conforme estudado, o STF, como regra geral, **não aceita o fenômeno da constitucionalidade superveniente** (cf. *item 4.8.1.2*).⁴ Nesse sentido:

“Constitucionalidade superveniente — Artigo 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718, de 27

“Constitucionalidade superveniente — Artigo 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998 — Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Tributário — Institutos — Expressões e vocábulos — Sentido. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. Contribuição Social — PIS — Receita Bruta — Noção — Inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 3.º da Lei n. 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1.º do artigo 3.º da Lei n. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada” (RE 346.084, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.11.2005, *DJ* de 1.º.09.2006). No mesmo sentido: RE 390.840, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.11.2005, *DJ* de 15.08.2006; RE 357.950, j. 09.11.2005, *DJ* de 15.08.2006.

■ 19.2.5. Cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para sociedades civis de profissões regulamentadas

■ 19.2.5.1. Inexistência de hierarquia entre LC e LO

O tema é muito interessante, não só em razão dos aspectos financeiros que envolve, mas, especialmente, ao nosso objetivo neste trabalho — analisar se há ou não hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. [5](#)

O art. 6.º, II, da LC n. 70/91 estabeleceu a **isenção** da **COFINS** para as sociedades civis prestadoras de serviços de profissão legalmente regulamentada.

Por sua vez, o art. 56 da Lei n. 9.430/96 revogou a referida isenção: “As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei Complementar n. 70, de 30 de dezembro de 1991”.

Assim, grande questão se colocou: poderia uma lei ordinária revogar artigo de lei complementar?

Duas correntes surgiram. A primeira entendia que LO não poderia revogar artigo de LC, tendo em vista o **princípio da hierarquia** entre LC e LO e, ainda, o critério da **impossibilidade de lei geral posterior revogar lei especial anterior**. Na linha da hierarquia das normas, várias decisões do STJ caminharam nesse sentido (cf., por exemplo: AgREsp 253.984/RS, *DJ* de 18.09.2000, REsp 221.710/RJ, *DJ* de 18.02.2002), tendo sido, inclusive, em 14.05.2003 (*DJ* de 02.06.2003) editada a **S. 276/STJ**: “As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da Cofins, irrelevante o regime tributário adotado”.

No STF, contudo, a tendência era diferente. No julgamento do RE 419.629, a 1.^a Turma entendeu que não existe hierarquia entre LC e LO, mas, em realidade, âmbito material a ser regulamentado. Algumas matérias são regulamentadas por LC. Assim, se uma LO tratar do assunto, ela será inconstitucional por violar a própria regra de competência da CF/88.

No caso concreto da isenção da COFINS, conforme visto anteriormente no *item 19.2.3*, o STF entendeu que a regulamentação das matérias do art. 195, I-IV, materializa-se por **lei ordinária** e no exercício da denominada **competência discriminada** da União, não se aplicando, assim, a regra do art. 146, III, “a” (que exige LC para a modalidade **imposto** de tributo), nem a regra do art. 195, § 4.º, que trata de outras fontes de custeio da seguridade social, na denominada **competência residual** da União.

Dessa maneira, a isenção conferida por LC poderia ter sido estabelecida por LO. Vale dizer, a LC n. 70/91 tem forma de LC, mas **essência**, “alma”, de LO. Logo, por ter *status* de LO, a revogação da isenção concedida poderia ter sido,

como foi, veiculada por LO. Vejamos:

“Contribuição social (CF, art. 195, I): legitimidade da revogação pela L. 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pela Lei Complementar 70/91, dado que essa lei, **formalmente complementar**, é, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída, **materialmente ordinária**; ausência de violação ao princípio da hierarquia das leis, cujo respeito exige seja observado o âmbito material reservado às espécies normativas previstas na Constituição Federal. Precedente: ADC 1, Moreira Alves, *RTJ* 156/721” (RE 457.884-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.02.2006, *DJ* de 17.03.2006). No mesmo sentido: RE 419.629, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23.05.2006, *DJ* de 30.06.2006; AI 637.299-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.09.2007, *DJ* de 05.10.2007. Cf., também, *Inf.* 459/STF.

O STF consagrou, portanto, a tese da inexistência de hierarquia entre LC e LO. No fundo, o conflito supostamente existente será de **competência constitucional**. Eventual LO que trate de assunto reservado a LC será inconstitucional não por violar a LC em si, mas por violar a própria CF/88.

De todo o exposto, diante da posição firmada pelo STF, julgando a **AR 3.761-PR**, na sessão de **12.11.2008**, a Primeira Seção do **STJ** deliberou pelo **cancelamento** da **S. 276** e, em momento seguinte, editou a **S. 508** com os seguintes dizeres: “a isenção da COFINS concedida pelo art. 6.º, II, da LC n. 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi **revogada** pelo art. 56 da Lei n. 9.430/96” (j. 26.03.2014, *DJE* de 30.03.2014).

■ 19.2.5.2. A questão da modulação dos efeitos da decisão pelo STF

Destacamos os julgamentos dos **REs 377.457** e **381.964**, nos quais se discutia o tema da revogação da isenção. Como o STF entendeu pela constitucionalidade da cobrança, restou a questão sobre conceder ou não a modulação dos efeitos da decisão.

Como se sabe, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista **razões de**

segurança jurídica ou de **excepcional interesse social**, poderá o STF, por maioria de 2/3 (pelo menos 8 Ministros) de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Não há dúvida de que o STF pode, por analogia, aplicar referida regra também ao controle difuso, até porque a tese julgada passa a servir de parâmetro para outros recursos extraordinários já interpostos e sobrestados (art. 543-B, § 3.º, do CPC, com correspondência mais ampliada nos arts. 1.039 e 1.040, CPC/2015).

Contudo, em **17.09.2008**, o STF não aceitou a modulação dos efeitos da decisão. A votação ficou empatada em 5 x 5 e, portanto, não se conseguiu o número mínimo de 8 Ministros para se aplicar a modulação dos efeitos da decisão.

Parece-nos que as críticas feitas por alguns Ministros que defendiam a modulação são muito pertinentes, especialmente por ter vigorado, por 5 longos anos, uma **súmula do STJ** (a de n. 276, como visto acima) fixando uma posição completamente oposta a essa nova do STF.

Segundo sustentou o Min. *Menezes Direito*, essa divergência de julgamentos “pode gerar uma insegurança jurídica e consequências terrificantes”. Em igual sentido, o Min. *Celso de Mello*, em face do tempo durante o qual perdurou o entendimento firmado na S. 276/STJ, argumentou: “esse longo período consolidou justas expectativas no espírito dos contribuintes, incutindo neles a confiança da plena regularidade da sua conduta, que se pautou segundo os cânones estabelecidos no enunciado” (*Notícias STF*, 17.09.2008).

O Min. *Cezar Peluso*, no entanto, “... rejeitou a modulação por não ver densidade jurídica que justificasse a tese. ‘Não podemos baratear o uso analógico da modulação, sob o risco de ter de modular toda a alteração feita sobre o entendimento dos tribunais’. Ele defendeu que as decisões da Corte têm de sinalizar para o contribuinte que ele leve a sério suas obrigações tributárias” (*Notícias STF*, 17.09.2008).

Assim, por 8 x 2 (no mérito — lembrando que 5 x 5 foi a discussão sobre a

modulação ou não da cobrança), entendeu o STF que os **profissionais liberais** (sociedades civis de prestação de serviços legalmente regulamentados) estão obrigados a recolher a Cofins, não tendo havido a modulação dos efeitos da decisão.⁶

■ 19.3. EDUCAÇÃO — FUNDEB — EC N. 53/2006

Esse importante tema da **educação** ainda precisa ser mais bem desenvolvido por nós, daí nos limitarmos, por enquanto, a apresentar as principais novidades trazidas pela EC n. 53/2006, pelo que **pedimos escusas aos nossos ilustres leitores**.

■ 19.3.1. Aspectos gerais

A **EC n. 53, de 19.12.2006**, é fruto da conversão da *PEC n. 9, de 2006 — SF (n. 536, de 1997, CD)*, dando nova redação aos arts. 7.º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do ADCT.

Como anota o Senador José Jorge em seu parecer na CCJ, “em linhas gerais, trata-se da **ampliação do mecanismo de financiamento do ensino fundamental público**, oferecido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e inaugurado pela Emenda à Constituição n. 14, de 1996...”.

A EC n. 14/96 criou o *FUNDEF — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério*, com prazo para vigorar por 10 anos e, assim, com término previsto para 2006.

Com o fim do *FUNDEF*, a **EC n. 53/2006**, ao criar o *FUNDEB*, torna o fundo mais abrangente e com prazo de 14 anos, com início em 2007 e término previsto para 2021.

Isso porque, enquanto o **FUNDEF** (*Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério*) buscava o aperfeiçoamento do **ensino fundamental**, o **FUNDEB** (*Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos*

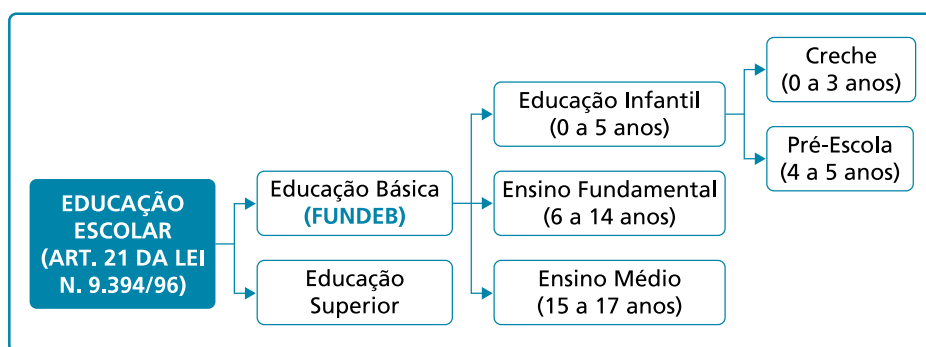
Profissionais da Educação) procura ampliar os mecanismos de financiamento da **educação básica**, na medida em que, além de cobrir o ensino fundamental, abrange, também, a educação infantil (creche e pré-escola) e o ensino médio.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 9.394/96 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), a **educação escolar** compõe-se de: **a)** educação básica, composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; **b)** educação superior.

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (art. 22 da lei).

■ 19.3.2. Quadro esquematizado da educação escolar

Acrescentamos, para facilitar o estudo, quadro ilustrativo da **educação escolar**, destacando o direcionamento do **FUNDEB** para toda a educação básica e não nos restringindo ao ensino fundamental:[7](#)



■ 19.3.3. Regras gerais do fundo

■ **Vigência:** 14 anos, a partir da promulgação da EC n. 53/2006.

■ **Destinação:** manutenção e desenvolvimento da **educação básica**, qual seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

■ **Fontes de recursos:** 20% dos **impostos** e **transferências estaduais** mais 20% das **transferências municipais** (observando que os impostos municipais não entram na composição do Fundo). Referida fonte deverá ser implementada gradativamente:

1) *Contribuição de Estados, DF e Municípios:* **a)** 16,66% no 1.º ano; **b)** 18,33% no 2.º ano; **c)** 20% a partir do 3.º ano, sobre: Fundo de Participação dos Estados — FPE; Fundo de Participação dos Municípios — FPM; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS; Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações — IPIexp; Desoneração de Exportações (LC n. 87/96);

2) *Contribuição de Estados, DF e Municípios:* **a)** 6,66% no 1.º ano; **b)** 13,33% no 2.º ano; **c)** 20% a partir do 3.º ano, sobre: Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doações — ITCMD; Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores — IPVA; quota-parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios — ITR;

3) *Previsão de complementação dos recursos pela União:* nos termos dos incisos V, VI e VII do art. 60 do ADCT. O não cumprimento do disposto nos incisos V e VII do *caput* do art. 60 do ADCT importará **crime de responsabilidade** da autoridade competente.

■ **Valorização dos profissionais da educação:** nos termos do art. 60, XII, do ADCT, pelo menos 60% do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício (“direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional”).⁸

Nesse sentido, estabelece o art. 206, V, da CF/88 como princípio básico do ensino a **valorização dos profissionais da educação escolar**, garantindo, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Além disso, na linha de valorização do profissional, o art. 206, VIII, fixa a previsão de **piso salarial profissional nacional** para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

■ **Uso dos recursos:** “manutenção e desenvolvimento da educação: construção, ampliação e reforma de escolas; equipamentos; material didático; transporte escolar; formação de profissionais, entre outras. NÃO PODE: despesas com alimentação, assistência médica, odontológica e social”.[9](#)

■ **Salário-educação:** vinculado à educação básica. Conforme o art. 212, § 5.º, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. O § 6.º do art. 212 completa que as cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

■ **Distribuição dos recursos do fundo:** com base no número de alunos da educação básica. Para efeito de distribuição dos recursos, levar-se-á em conta a **totalidade** das matrículas no ensino fundamental (100%), e considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 das matrículas no primeiro ano, 2/3 no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano (art. 60, § 4.º, do ADCT).

■ **19.3.4. Fim (progressivo) da DRU para a educação e as ECs ns. 59/2009 e 68/2011**

O art. 2.º da Lei n. 4.320/64 prevê que a Lei do Orçamento conterá a discriminação da **receita** e **despesa** de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

Observa-se, assim, um alto grau de vinculação no orçamento brasileiro, como as transferências constitucionais, seguridade social, manutenção e desenvolvimento do ensino etc.

De acordo com o art. 76 do ADCT, contudo, foi retomado o mecanismo de se **Desvincular Recursos da União** (DRU): “são desvinculados de órgão, fundo

ou despesa, até **31.12.2015**, **20%** da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais”.

O objetivo da **DRU** é “... dar uma maior flexibilidade à alocação dos recursos públicos e não significa elevação das receitas disponíveis para o governo federal. Além disso, não afeta as transferências constitucionais para Estados e municípios, cuja principal fonte de receita é o IPI e o Imposto de Renda, uma vez que a desvinculação é feita após os cálculos das transferências”. As suas finalidades podem ser: **a)** permitir a alocação mais adequada de recursos orçamentários; **b)** não permitir que determinados itens de despesas fiquem com excesso de recursos vinculados, ao mesmo tempo que outras áreas apresentam carência de recursos; **c)** permitir o financiamento de despesas incomprimíveis sem endividamento adicional de União” (*www.planejamento.gov.br*).

A base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a das destinações a que se reporta o art. 159, I, “c”, estão garantidas pela ressalva contida do no art. 76, § 1.º, do ADCT.

Também, excetua-se da aludida desvinculação a arrecadação da contribuição social do **salário-educação** a que se refere o art. 212, § 5.º.

A **EC n. 59/2009**, por sua vez, inovou ao acabar com a DRU — Desvinculação de Receitas da União — para a **educação**. Essa desvinculação, como se observava da redação conferida ao § 3.º do art. 76 do ADCT, dar-se-ia de modo **gradativo**: “para efeito do cálculo dos recursos para **manutenção e desenvolvimento do ensino** de que trata o art. 212 da Constituição, o percentual referido no *caput* deste artigo será de 12,5% no exercício de 2009, 5% no exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011”.

Nesse sentido, a **EC n. 68/2011**, ao dar nova redação ao art. 76, § 3.º, do ADCT, estabeleceu que, para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal, o percentual referido no *caput* será **nulo**, confirmando, portanto, a previsão fixada pela EC n. 59/2009.

Assim, segundo noticiado, “a previsão é que com a extinção da desvinculação, a Educação recebesse em 2009 cerca de R\$ 4 bilhões, de um total previsto de R\$ 41 bilhões. Em 2010, o fim da DRU para a educação representará “injeção de novos R\$ 8 bilhões para o ensino” (*Notícias STF*, 11.11.2009).

Não parece que isso seja suficiente para resolver o grave problema de educação no Brasil, porém é uma garantia de que os governantes aplicarão um valor mínimo nesse tema essencial para o crescimento do País. Naturalmente que os orçamentos deverão preocupar-se além desse mínimo.

Outro ponto de suma importância trazido pela EC n. 59/2009 foi o aumento da escolaridade obrigatória.

Agora, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos **4** aos **17 anos** de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (art. 208, I).

Essa **extensão** da **garantia da obrigatoriedade do ensino** (que antes da EC n. 59/2009 era apenas para o ensino fundamental) deverá ser implementada progressivamente, até **2016**, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União.

Para alcançar esse objetivo, agora o art. 211, § 4.º, passa a incluir a **União** no regime de colaboração, responsabilidade essa que não poderia ficar só com os Estados e Municípios: na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão **formas de colaboração**, de modo a assegurar a **universalização do ensino obrigatório**.

A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do **ensino obrigatório**, no que se refere a **universalização**, **garantia de padrão de qualidade e equidade**, nos termos do plano nacional de educação que passou a ter duração **decenal** (art. 214, *caput*).

■ 19.4. CULTURA

Assim como a educação, também este importante tema da **cultura** está em processo de análise e desenvolvimento. Novamente, pedimos escusas ao nosso ilustre leitor, concentrando-nos nas novidades introduzidas pelas ECs ns. 48/2005 e 71/2012.

■ 19.4.1. Plano Nacional de Cultura (EC n. 48/2005)

O art. 215 da CF/88 consagra como direito fundamental o **princípio da cidadania cultural** ao prescrever que o Estado garantirá a todos o **pleno exercício dos direitos culturais** e o **acesso às fontes da cultura nacional**, e apoiará e incentivará a **valorização** e a **difusão das manifestações culturais**.

E os parágrafos do art. 215 estabelecem que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, e que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

O art. 216 da CF/88, por sua vez, define a amplitude do conceito de **patrimônio cultural** como os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

A Constituição, no entanto, deixou de prever expressamente, a exemplo do que se fixou no art. 214 no que tange à educação, um **plano nacional de cultura**, situação essa agravada pela falta de prioridade dos governantes em relação a tão importante direito fundamental.

Durante a tramitação do projeto, o então Senador Hélio Costa lembra interessante frase do ex-Ministro da Cultura da França *Jacques Lang*: “as únicas

coisas no mundo que deveriam ter subsídios governamentais são a cultura e a agricultura, porque os alimentos para a alma são tão necessários quanto os alimentos para o corpo” (DSF de 02.06.2005, p. 17142).

Ao comentar sobre a necessidade de um **plano nacional de cultura**, o Senador Marcelo Crivella sinalizou que se tratava “... de uma iniciativa do Governo Federal da maior relevância. Estamos sendo aculturados por potências estrangeiras hegemônicas, porque não temos ainda, neste País, um plano nacional que valorize a nossa cultura, que destine recursos suficientes e que organize desde os nossos sites antropológicos, onde estão (*sic*) a história dos nossos ancestrais, até mesmo uma organização consistente, um arcabouço completo da nossa cultura, das nossas festas, da nossa música, da nossa poesia, dos nossos quadros, principalmente da nossa história, para que os brasileiros não cometam os erros do passado. O Plano Nacional de Cultura é fundamental tanto no seu conselho gestor como no seu fundo. É um momento importante em que o Congresso Nacional e o Senado Federal dão uma manifestação concisa, definitiva para que fique valorizada e preservada para as futuras gerações a cultura do nosso povo...” (DSF de 02.06.2005, p. 17142).

Na *justificativa* da proposição, estabelece-se, com propriedade, que a Cultura “... é um vetor indispensável do desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. É ela, em última instância, o elemento definidor da identidade nacional em um mundo pretensamente ‘sem barreiras’, em virtude do processo de globalização” (DSF de 07.08.2003, p. 22449).

Nesse contexto, positivamente, o Congresso Nacional aprovou a **EC n. 48**, de 10.08.2005, prescrevendo que a lei estabelecerá o **Plano Nacional de Cultura**, de duração **plurianual**, visando ao **desenvolvimento cultural do País** e à **integração das ações do Poder Público** que conduzem à:

- defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
- produção, promoção e difusão de bens culturais;
- formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;

- democratização do acesso aos bens de cultura;
- valorização da diversidade étnica e regional.

Segundo José Afonso da Silva, “o direito à cultura é um direito constitucional que exige ação positiva do Estado, cuja realização efetiva postula uma política cultural oficial. A ação cultural do Estado há de ser ação afirmativa que busque realizar a igualação dos socialmente desiguais, para que todos, igualmente, aufram os benefícios da cultura”. [10](#)

Sem dúvida, portanto, a **EC n. 48/2005** significa avanço em prol da efetivação desse importante valor constitucional e direito fundamental chamado **cultura**. Esperamos, apenas, que o **plano nacional de cultura** se efetive, encontrando o seu espaço e prioridade nos planos de governo, sem prejuízo do andamento das demais políticas públicas e implementação de outros tantos programas prometidos, como o da **educação**, o da **erradicação da pobreza** e, de modo geral, **os direitos civis, políticos, sociais e econômicos**. Resta, com esperança, aguardar e cobrar atitude positiva de nossos governantes, colocando em prática real e efetivamente o importante e necessário **plano nacional de cultura**.

■ 19.4.2. Sistema Nacional de Cultura (EC n. 71/2012)

Com o objetivo de efetivar as políticas públicas envolvendo a cultura no Brasil, a **EC n. 71/2012** previu mais um instrumento de aperfeiçoamento, assim como já se observara com a criação do *Plano Nacional de Cultura* (EC n. 48/2005).

Trata-se da instituição do denominado **Sistema Nacional de Cultura**, que será organizado em regime de **colaboração**, de forma **descentralizada** e **participativa**, estabelecendo-se um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

De acordo com o art. 216-A, § 1.º, o *Sistema Nacional de Cultura* fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no *Plano Nacional de Cultura*, e rege-se pelos seguintes princípios:

- diversidade das expressões culturais;
- universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
- fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
- cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;
- integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
- complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
- transversalidade das políticas culturais;
- autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
- transparência e compartilhamento das informações;
- democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
- descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
- ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

Caberá a **lei federal** dispor sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo, sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em **leis próprias**.

■ 19.5. DESPORTO

■ 19.5.1. Desporto em sentido amplo

O desporto está previsto em sentido amplo no texto de 1988, não se restringindo somente ao esporte, mas englobando também a ideia de **recreação, lazer, divertimento**, uma vez que o Poder Público incentivará o lazer como forma de **promoção social** (art. 217, § 3.º).

Cabe lembrar, conforme já visto, que o *lazer* está arrolado no art. 6.º como **direito social**, apresentando íntima relação com a ideia de qualidade de vida. [11](#)

Araujo e Nunes Júnior, ao discorrerem sobre o desporto, afirmam que “os direitos sociais objetivam a formação do ser humano integral: agente da sociedade, das relações de trabalho, construtor do mundo moderno e, ao mesmo tempo, um ser relacional, humano, que, desse modo, deve integrar sua vida com o lazer, o convívio familiar e a prática desportiva. Assim, o desporto, quer como forma de lazer, quer como parte da atividade educativa, quer ainda em caráter profissional, foi incorporado ao nosso sistema jurídico no patamar de norma constitucional”. [12](#)

■ 19.5.2. Modalidades de desporto

Nos termos do art. 217, *caput*, I a IV, da CF/88, bem como dos arts. 1.º e 3.º da Lei n. 9.615/98 (**Lei Pelé**, que *institui normas gerais sobre desporto e prevê outras providências*), o desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:

■ **desporto formal**: regulado por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto;

■ **desporto não formal**: caracterizado pela liberdade lúdica de seus praticantes. *Lúdico*, segundo o dicionário *Aurélio*, pode ser definido como *referente a, ou que tem o caráter de jogos, brinquedos e divertimentos*; [13](#)

■ **desporto educacional**: praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando a seletividade e a

hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;

■ **desporto de participação:** chamado de *amador*, é aquele praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente. O dever do Estado concerne à preservação de parques, áreas verdes, praias, lagos, com o objetivo de facilitar a prática desse *desporto de lazer*;

■ **desporto de rendimento:** praticado segundo normas gerais da *Lei Pelé* e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações. Trata-se do desporto de competição, podendo ser organizado e praticado de modo *profissional* ou *não profissional*, tendo a Constituição determinado o tratamento diferenciado entre um e outro (art. 217, III, da CF/88);

■ **desporto de rendimento profissional:** caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva, inclusive podendo a remuneração ser por meio de patrocínio;

■ **desporto de rendimento não profissional:** identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, permitindo o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

■ 19.5.3. Papel do Estado e das entidades dirigentes e associações na promoção do desporto

Ao **Estado** é atribuído o dever de **fomentar** as práticas desportivas formais e não formais (art. 217, *caput*, da CF/88). Fomentar deve ser entendido com o significado de estimular, facilitar, desenvolver. Trata-se de direito (subjetivo) de cada um.

Se, por um lado, o papel do Estado é de fomento, por outro, o papel de

prestação foi atribuído às **entidades desportivas dirigentes** e **associações** com autonomia para sua **organização** e **funcionamento** (art. 217, I), significando importante desdobramento da regras contidas nos arts. 5.º, XVII, e 8.º da CF/88.

■ 19.5.4. Destinação dos recursos públicos para o desporto

A destinação de **recursos públicos** para a promoção do desporto deverá ser (art. 217, II):

- **prioritária:** para o desporto educacional;

- **em casos específicos:** para o desporto de alto rendimento, nesse caso, lembrando que o desporto de alto rendimento pode ser classificado em profissional e não profissional e, ainda, na medida em que o tratamento entre eles deverá ser diferenciado (art. 217, III), parece que a priorização deve ser direcionada ao desporto não profissional.

Nesse contexto, vejamos a decisão do STF sobre o assunto: “1. É inconstitucional a lei complementar distrital que cria programa de incentivo às atividades esportivas mediante concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e investimentos em favor de atletas ou pessoas jurídicas. 2. O ato normativo atacado faculta a vinculação de receita de impostos, vedada pelo artigo 167, inciso IV, da CB/88. Irrelevante se a destinação ocorre antes ou depois da entrada da receita nos cofres públicos. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da vinculação do imposto sobre propriedade de veículos automotores — IPVA, contida na LC 26/97 do Distrito Federal” (ADI 1.750, Rel. Min. Eros Grau, j. 20.09.2006, *DJ* de 13.10.2006).

■ 19.5.5. Manifestações desportivas de “criação nacional”

Assegura o art. 217, IV, a **proteção** e o **incentivo** às manifestações desportivas de **criação nacional**.

Conforme anota José Afonso da Silva, *criação nacional* “... não significa que seja de invenção brasileira, mas que seja prática desportiva que já se tenha incorporado aos hábitos e costumes nacionais”.[14](#)

■ 19.5.6. Justiça Desportiva

■ 19.5.6.1. Regras gerais, natureza jurídica e composição

Prevista nos §§ 1.º e 2.º do art. 217, a **Justiça Desportiva não integra o Poder Judiciário**, portanto não está arrolada no art. 92 da CF/88. Trata-se de **órgão administrativo**.

A Justiça Desportiva tem a atribuição de julgar, exclusivamente, as questões relacionadas à **disciplina** e às **competições desportivas**.

Nos termos do art. 50, *caput*, da Lei n. 9.615/98 (*Lei Pelé*), na redação dada pela Lei n. 12.395/2011, a organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, *limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas*, serão definidos nos Códigos de Justiça Desportiva, facultando-se às ligas constituírem seus próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação restrita às suas competições.

Compete às entidades de **administração do desporto** (federação e confederação) promover o **custeio** do funcionamento dos órgãos da Justiça Desportiva que atuem junto a si (*Lei Pelé*, art. 50, § 4.º).

Quanto aos órgãos integrantes da Justiça Desportiva, estabelece o art. 52 da *Lei Pelé* que são autônomos e independentes das referidas entidades de administração do desporto de cada sistema, compondo-se de:

- **Superior Tribunal de Justiça Desportiva:** funcionando junto às entidades nacionais de administração do desporto;
- **Tribunais de Justiça Desportiva:** funcionando junto às entidades regionais da administração do desporto;
- **Comissões Disciplinares:** com competência para processar e julgar as

questões previstas nos Códigos de Justiça Desportiva.

■ **19.5.6.2. Instância administrativa de curso forçado: exceção ao princípio do acesso incondicionado ao Poder Judiciário. Necessidade de esgotamento das vias administrativas**

A Constituição instituiu verdadeira **condição de procedibilidade** para a apreciação jurisdicional das questões relativas à disciplina e às competições desportivas, uma vez que o Poder Judiciário só admitirá ações de tal natureza após **esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva**, que terá prazo máximo de **60 dias**, contados da instauração do processo administrativo, para proferir decisão final.

Trata-se da instauração da denominada *instância administrativa de curso forçado*. Findo tal prazo, “abrem-se as portas” para o Poder Judiciário, mesmo que o julgamento pela Justiça Desportiva ainda não tenha terminado.

Indagação importante que se coloca é se o Poder Judiciário pode apreciar qualquer questão antes de se instaurar o processo administrativo ou durante os 60 primeiros dias contados de sua instauração.

De modo geral, o constituinte originário estabeleceu expressa exceção ao princípio da inafastabilidade (art. 5.º, XXXV), não podendo o Judiciário apreciar nenhuma questão relacionada à *disciplina* e às *competições desportivas* antes de se instaurar o processo administrativo ou, uma vez iniciado o julgamento administrativo, durante os 60 primeiros dias contados de sua instauração.

Entretanto, inaugurado o processo administrativo, parece-nos perfeitamente possível o Judiciário analisar questões relacionadas à legalidade ou à constitucionalidade, ou seja, se alguma regra procedimental ou de direito constitucional está sendo violada pela Justiça Desportiva. O mérito do julgamento, contudo, está restrito a uma análise inicial e dentro do prazo de 60 dias a contar da instauração do processo na Justiça Desportiva.

O objetivo da regra é evitar tumulto durante determinada competição desportiva.

■ 19.5.6.3. *Questões trabalhistas: competência da Justiça do Trabalho*

Como se verificou, a competência da *Justiça Desportiva*, que não integra o Poder Judiciário e, assim, instaura o processo em inegável contencioso administrativo, é somente para as **questões relativas à disciplina** e às **competições desportivas**.

Portanto, a competência para apreciar e julgar questões **trabalhistas** que decorram do contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva (desporto profissional) será da **Justiça do Trabalho**. [15](#)

A nova regra fixada pela CF/88 (arts. 114, I, e 217, § 1.º) e pela Lei n. 9.615/98 (art. 50, *caput*) prevalece sobre a regra **anterior**, prevista na Constituição de 1967 e no art. 29 da **revogada** Lei n. 6.354/76, que exigia o prévio esgotamento das vias administrativas, pela Justiça Desportiva, antes de se ingressar com a demanda na Justiça do Trabalho para tratar de causas oriundas da relação de trabalho.

O citado art. 50 da Lei n. 9.615/98, na redação dada pela Lei n. 12.395/2011, como visto, estabelece que a organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva limitam-se, **exclusivamente**, ao processo e julgamento das **infrações disciplinares** e às **competições desportivas**, conforme delimitação pelos Códigos de Justiça Desportiva.

■ 19.5.6.4. *Vedação do exercício de funções na Justiça Desportiva por integrantes do Poder Judiciário*

A **Res. n. 10/2005-CNJ**, considerando que os integrantes do Poder Judiciário estão submetidos ao art. 95, parágrafo único, I, da CF/88 (que veda aos juízes, ainda que em disponibilidade, o exercício de outro cargo ou função, salvo uma de magistério), e, ainda, de acordo com o regime disciplinar estipulado nos arts. 35 e seguintes da LC n. 35/79 (*LOMAN*), vedou o exercício, pelos integrantes do Poder Judiciário, de funções nos Tribunais de Justiça Desportiva e em suas Comissões Disciplinares.

Referida resolução determinou aos membros do Poder Judiciário que exerciam funções nos Tribunais de Justiça Desportiva e em suas Comissões Disciplinares que se desligassem dos respectivos órgãos até o dia 31.12.2005.

Segundo noticiado, de acordo com o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Antonio de Pádua Ribeiro, em 2005 eram cerca de 100 magistrados que atuavam na Justiça Desportiva: “Para o ministro, não é permitido ao desembargador o exercício de cargo de direção ou cargo técnico de sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza ou finalidade. Essa, como argumentou em seu voto, é a forma que a sociedade encontrou de assegurar a independência e o cumprimento, pelo magistrado, de seus deveres e funções, com presteza, correção e pontualidade” (*Notícias STF*, 23.12.2005).

Contra a Res. n. 10/2005-CNJ foi impetrado o **MS 25.938**, buscando torná-la “sem efeito” para os impetrantes. A liminar foi indeferida, e a PGR opinou pela extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito, com base na Súmula 266 do STF.

Entendemos que agiu corretamente o CNJ ao **proibir** que os juízes de direito integrem os quadros da Justiça Desportiva. De um lado, em face da explícita vedação contida no art. 95, parágrafo único, I, de outro, diante da ideia de efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, como determina o art. 5.º, LXXVIII (EC n. 45/2004).

Seguindo essa tendência, declarou o STF **constitucional** a Res. n. 10/2005-CNJ e, portanto, a proibição do exercício de funções pelos magistrados no TJD e em suas Comissões Disciplinares:

“EMENTA: Mandado de segurança. Resolução n. 10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Vedação ao exercício de funções, por parte dos magistrados, em tribunais de justiça desportiva e suas comissões disciplinares. Estabelecimento de prazo para desligamento. Norma proibitiva de efeitos concretos. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. **Impossibilidade de acumulação do cargo de juiz com qualquer outro, exceto o de magistério.** A proibição jurídica é sempre uma ordem, que há de ser cumprida sem que qualquer outro provimento administrativo tenha de ser praticado... As vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, **proteger o próprio**

Poder Judiciário, de modo que seus integrantes sejam dotados de condições de **total independência** e, de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às funções inerentes ao cargo, **proibindo que a dispersão com outras atividades deixe em menor valia e cuidado o desempenho da atividade jurisdicional**, que é função essencial do Estado e direito fundamental do jurisdicionado. O **art. 95, parágrafo único, inc. I**, da Constituição da República vinculou-se a uma proibição geral de acumulação do cargo de juiz com qualquer outro, de qualquer natureza ou feição, salvo uma de magistério” (MS 25.938, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.04.2008, *DJE* de 12.09.2008).

■ 19.5.7. Bingos

Os bingos foram previstos, entre outras normas, pela Lei n. 9.615/98 (*Lei Pelé*). Por sua vez, a Lei n. 9.981/2000 revogou a autorização de bingos a partir de 31.12.2001. Assim, todas as casas de bingos deixaram de ter autorização legal para continuar em funcionamento.

Em razão dessa realidade, muitas *leis estaduais* passaram a disciplinar o assunto. Entendeu o STF, contudo, que é **competência privativa da União** legislar sobre bingos, nos termos do **art. 22, XX**, que dispõe sobre sistemas de **consórcios** e **sorteios**. Para o STF, a expressão *sorteios* abrange os jogos de azar, loterias e similares, e, assim, os Estados-Membros, o DF e os Municípios não poderiam legislar sobre bingos, ainda que de maneira concorrente. Todas as casas de bingo perderam o sustentáculo legal para continuar abertas, e, até que a União legisle sobre o assunto, a tendência é o fechamento daquelas que estiverem funcionando exclusivamente com base em lei estadual, distrital ou municipal.

Nesse sentido, o STF editou a **Súmula Vinculante 2**: “*É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias*” (Sessão Plenária de 30.05.2007).

■ 19.6. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EC N. 85/2015)

■ 19.6.1. Perspectivas introduzidas pela EC n. 85/2015

A **EC n. 85, de 26.02.2015**, reforça a necessidade de valorização da **ciência**, da **tecnologia** e da **inovação**, com destaque para essa última.

A sua origem se deu em razão dos estudos e debates que surgiram durante a discussão, na Comissão Especial, para a apreciação do *PL n. 2.177/2011-CD*, que propõe a criação do *Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação* com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

A introdução da palavra **“inovação”** abre perspectivas importantes para o aperfeiçoamento no ambiente econômico, buscando novos produtos, processos, serviços e soluções e, assim, uma arrancada em nome da prosperidade, popularizando e incentivando a ciência.

A alteração da Constituição traz importantes avanços, destacando-se:

- ampliação das entidades que poderão receber apoio financeiro do Poder Público (art. 213, § 2.º);
- incentivo à cooperação entre órgãos dos setores público e privado, estimulando o intercâmbio de conhecimentos, inclusive com atuação no exterior;
- facilitação para o remanejamento de recursos financeiros por ato do próprio Poder Executivo, sem a necessidade da prévia autorização legislativa (art. 167, § 5.º);
- ciência, tecnologia, pesquisa e inovação são atribuições de todos os entes federativos, que deverão implementá-las de modo cooperativo, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, V, CF/88).

■ 19.6.2. O papel do Estado

Acompanhando a tendência (e necessidade) mundial, o art. 218, *caput*, na redação dada pela **EC n. 85/2015**, estabelece que o Estado *promoverá e incentivará*:

- **o desenvolvimento científico;**
- **a pesquisa;**
- **as capacitações científica e tecnológica;**
- **a inovação.**

Promover deve ser entendido como o dever do Estado de, por si, realizar as tarefas derivadas da ciência, da tecnologia e da inovação, destacando-se aqui o papel das Universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e institutos de pesquisa.

Para esse fim, em 15.03.1985, foi criado, pelo Decreto n. 91.146, o *Ministério da Ciência e Tecnologia*, posteriormente melhor denominado *Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)*, órgão da administração direta, que tem como área de competência os seguintes assuntos, nos termos do art. 1.º do Anexo I do Decreto n. 5.886/2006:

- política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação;
- planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
- política de desenvolvimento de informática e automação;
- política nacional de biossegurança;
- política espacial;
- política nuclear; e
- controle da exportação de bens e serviços sensíveis.

Incentivar, por sua vez, significa que o Estado deverá estimular a produção científica, a pesquisa, as capacitações científica e tecnológica, a inovação, e, para tanto, deverá estabelecer incentivos, inclusive para as instituições privadas.

■ 19.6.3. Modalidades de pesquisa e o tratamento prioritário do Estado

O art. 218, §§ 1.º e 2.º, prevê duas espécies de pesquisa: a pesquisa *científica básica* e a *pesquisa tecnológica*.

Com a inovação introduzida pela **EC n. 85/2015**, não apenas a pesquisa científica básica, mas, agora, também, a tecnológica, receberão **tratamento prioritário do Estado**, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

De acordo com o art. 218, § 2.º, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

■ 19.6.4. Apoio e incentivo do Estado

O Estado **apoiará a formação de recursos humanos** nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá, aos que delas se ocupem, meios e condições especiais de trabalho (**EC n. 85/2015**).

Como desdobramento dessa política de incentivos, determina o art. 218, § 4.º, que a **lei 16** apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

Nessa linha de apoio e incentivo, e para a capacitação tecnológica, excepcionando a regra geral do art. 167, IV, o art. 218, § 5.º, faculta aos **Estados** e ao **Distrito Federal** (e o constituinte não estendeu essa faculdade aos Municípios e à União) vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. [17](#)

O Estado estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

Dessa forma, as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por **universidades** e/ou por **instituições de educação profissional e tecnológica** poderão receber **apoio financeiro do Poder Público** (art. 213, § 2.º).

Destacamos essa importante novidade introduzida pela **EC n. 85/2015** que estendeu e ampliou para outras entidades a possibilidade de apoio financeiro do Poder Público, não mais restrito às atividades universitárias de pesquisa e extensão.

Nessa linha, o art. 167, § 5.º, introduzido pela EC n. 85/2015, trazendo maior liberdade, estabelece que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante **ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI do referido artigo**.

Ainda, o Estado promoverá e incentivará a **atuação no exterior** das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades ligadas a ciência, tecnologia e inovação.

Apesar de toda essa perspectiva trazida pela EC n. 85/2015, não podemos deixar de destacar o importante papel que já vem sendo desempenhado pelo CNPq, FAPESP e tantos outros órgãos e instituições de fomento e que, certamente, poderão implementar as suas atividades.

■ 19.6.5. Estado Social de Direito: concepção social do mercado

O art. 219 da CF/88 estatui que o **mercado interno** integra o **patrimônio nacional** e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

A previsão do *mercado interno* enquanto *patrimônio nacional* afasta, assim, a ideia liberal clássica e consagra uma perspectiva de Estado Social de Direito,

fixando uma **concepção social do mercado**.

O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Nessa linha, a EC n. 85/2015 trouxe importantes novidades ao explicitar a ideia de **cooperação** e **colaboração**:

■ **cooperação**: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades **públicos** e com entidades **privadas**, inclusive para o **compartilhamento** de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não, assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei;

■ **colaboração**: o *Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação* será organizado em regime de **colaboração** entre entes, tanto **públicos** quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

■ 19.6.6. O destaque para a biotecnologia

Ligada à tecnologia está a **biotecnologia** e todo o seu desdobramento, como a pesquisa com células-tronco embrionárias, a criação de organismos vivos ou geneticamente modificados, a clonagem (reprodutiva ou terapêutica), que deverá estar intimamente ligada à **ética**.

Na linha do que Norberto Bobbio chamou de **direitos fundamentais de 4.^a geração (ou dimensão)** (cf. *item 14.2* deste estudo), destacamos o julgamento da ADI 3.510, [18](#) declarando o STF a constitucionalidade do art. 5.º da Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105/2005) no tocante à pesquisa com células-tronco embrionárias (cf. *item 14.10.1*).

■ 19.7. COMUNICAÇÃO SOCIAL

O capítulo da *comunicação social* aparece com destaque no texto de 1988 (regulado, pela primeira vez, em capítulo específico e autônomo), marcando um momento histórico, qual seja, a redemocratização do País após mais de 20 anos de ditadura, com fortes restrições às liberdades democráticas e de imprensa.

Resgatamos a redação dada ao art. 399 do *Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos*, que, embora não aprovado, parece orientar a interpretação do Capítulo V do Título VIII da CF/88, colaborando para o conceito de **comunicação social**: “o sistema de comunicação social compreende a imprensa, o rádio e a televisão e será regulado por lei, atendendo à sua função social e ao respeito à verdade, à livre circulação e à difusão universal da informação, à compreensão mútua entre os indivíduos e aos fundamentos éticos da sociedade”.

Considerando a liberdade de comunicação, o pensamento e as informações podem ser exteriorizados por diferentes **meios de comunicação**, como, entre outros, o veículo impresso (livros, jornais, periódicos) ou o de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Conforme veremos, nos termos do art. 220, § 6.º, a publicação em **veículo impresso de comunicação** independe de licença de autoridade.

Já os serviços de **radiodifusão sonora e de sons e imagens** serão explorados diretamente pela União, ou mediante autorização, concessão ou permissão (arts. 21, XII, “a”, e 223).

Focaremos a análise nos veículos impressos e de *radiodifusão sonora e de sons e imagens*. Porém, é natural que se entenda que a previsão constitucional da comunicação social é concernente à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, **sob qualquer forma, processo ou veículo**, lembrando que as únicas restrições que poderão sofrer vêm contidas na Constituição.

Assim, a liberdade de comunicação social se implementa, como já se disse, por qualquer forma, tais como o jornal, a revista, o periódico, o rádio, a TV, o fax, o telefone, a Internet, *shows*, teatro etc.

Não se trata de liberdade irresponsável, visto que, enfatize-se, a comunicação social não sofrerá limitação, exceto, naturalmente, aquelas previstas na própria Constituição e que serão estudadas neste capítulo.

■ 19.7.1. Princípios orientadores da comunicação social

As diversas formas de comunicação social regem-se pelos seguintes princípios:

■ **inexistência de restrição:** a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição, observado o disposto na Constituição (liberdade de comunicação social). Isso significa, como já se disse, que só poderão ser restringidas nos termos e limites fixados na Constituição;

■ **plena liberdade de informação jornalística:** nenhuma lei conterà dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5.º, IV (liberdade de pensamento, vedado o anonimato); V (direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano material, moral ou à imagem); IX (proibição da censura); X (inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem, assegurando-se o direito à indenização); XIII (liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão); e XIV (liberdade de informar e ser informado).

Em interessante discussão, o MPF ajuizou *ação civil pública* perante a União, com a finalidade de extinguir a exigência de registro ou de inscrição no Ministério do Trabalho para o exercício da profissão de jornalista.

O juiz da 16.^a Vara Cível Federal de São Paulo/Capital julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que, em todo o País, não mais se exigisse o diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Referida decisão foi reformada pela 4.^a Turma do TRF-3. Diante desse fato, o MPF interpôs *recurso extraordinário* sustentando que o Decreto-lei n. 972/69, que estabelece requisitos para o exercício da profissão de jornalista, não teria sido recepcionado, especialmente diante da regra dos arts. 5.º, XIII, e 220, *caput*, e § 1.º, portanto

foi revogado.

Buscando dar efeito suspensivo ao referido RE, o MPF ajuizou ação cautelar (AC 1.406) com o objetivo de “garantir efetividade ao recurso extraordinário interposto e evitar a ocorrência de graves prejuízos àqueles indivíduos que estavam a exercer a atividade jornalística, independentemente de registro no Ministério do Trabalho ou de diploma de curso superior específico”. O Min. Relator, Gilmar Mendes, deferiu a medida cautelar, que foi referendada pelo Pleno, dando efeito suspensivo ao RE 511.961 e, assim, permitindo que qualquer pessoa desempenhe a atividade de jornalista sem a necessidade de apresentação do diploma.

Em 17.06.2009, por 8 x 1, o STF **derrubou a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista:**

‘EMENTA: O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das **liberdades de expressão e de informação**. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente **ao exercício pleno da liberdade de expressão**. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso implica, logicamente, que a interpretação do art. 5.º, inciso XIII, da Constituição, na hipótese da profissão de jornalista, se faça, impreterivelmente, em conjunto com os preceitos do art. 5.º, incisos IV, IX, XIV, e do art. 220 da Constituição, que asseguram as liberdades de expressão, de informação e de comunicação em geral. (...) No campo da profissão de jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O art. 5.º, incisos IV, IX, XIV, e o art. 220, não autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao acesso e exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística, configura, ao fim e ao cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art. 5.º, inciso IX, da Constituição. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão

jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de expressão e de informação. Jurisprudência do STF: Representação n. 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, *DJ*, 2-9-1977” (**RE 511.961**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.06.2009, Plenário, *DJE* de 13.11.2009).

Resta observar que tramita no Senado Federal a **PEC n. 33/2009**, que, com algumas ressalvas, passa a exigir o diploma de jornalista (**matéria pendente**). Assim, no momento da leitura, checar se referida PEC foi aprovada.

■ **Vedação à censura:** é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística (cf., ainda, art. 5.º, IX).

■ **Regulação estatal sobre as diversões e espetáculos:** compete à *lei federal* [19](#) regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza destes, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, estabelecendo-se, ainda, mecanismos de controle de defesa pessoal e familiar (arts. 220, § 3.º, I e II, e 21, XVI).

Sobre esse importante assunto, existe matéria pendente de julgamento no STF. Trata-se da **ADI 2.404**, na qual se discute a constitucionalidade do art. 254 do *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)*, que caracteriza como **infração administrativa** a transmissão, por meio de rádio ou televisão, de espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação, estabelecendo pena de multa, podendo, ainda, em caso de reincidência a autoridade judiciária determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.

Até o fechamento desta edição, 4 Ministros já tinham se posicionado no sentido de que as emissoras podem definir **livremente** a programação a ser exibida, estando obrigadas, contudo, apenas a **divulgar a classificação indicativa** realizada pelo Poder Público (**matéria pendente** — *pedido de vista pelo Min. Joaquim Barbosa em 30.11.2011*).

■ **Regulação estatal em relação ao tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias:** a propaganda comercial sobre esses produtos estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do § 3.º do art. 220, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso (cf. Lei n. 9.294/96). [20](#)

■ **Vedação de monopólio ou oligopólio na comunicação social:** os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio (cf. art. 173, § 4.º), assegurando-se, assim, a multiplicidade de agentes de informação e, portanto, o acesso mais igualitário à informação.

■ **Publicação de veículo impresso de comunicação:** independe de licença de autoridade.

■ **Produção e programação das emissoras de rádio e TV:** sofrerão controle de qualidade por parte do Estado, devendo respeitar a cultura nacional e regional, bem como os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

■ **Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens:** privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País, observando-se as regras do art. 222 (cf. *item 19.7.3*).

■ **Serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens:** compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a sua concessão, permissão e autorização, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal e havendo, ainda, controle pelo Congresso Nacional (art. 223, §§ 1.º a 5.º).

■ 19.7.2. Princípios a orientar a produção e a programação das emissoras de rádio e TV

A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios (art. 221):

- preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
- promoção da cultura nacional e regional e estímulo à *produção independente* que objetive sua divulgação;
- regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

■ 19.7.3. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

Segundo a redação original do art. 222 da CF/88 **antes** da reforma trazida pela **EC n. 36/2002**, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens era, por regra geral, privativa de pessoas físicas (brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos), vedando-se a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa. Excepcionalmente, *sem qualquer direito a voto e limitada a 30% do capital social*, permitia-se a participação de *partido político* e de *sociedades* cujo capital pertencesse exclusiva e nominalmente a brasileiros.

De acordo com a nova redação conferida ao art. 222, *caput*, pela **EC n. 36/2002**, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa:

- de **brasileiros natos**; ou
- de **brasileiros naturalizados há mais de dez anos**; ou
- de **pessoas jurídicas** constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

O art. 222, § 1.º, inovando, dispôs que pelo menos **70% do capital total** e do **capital votante** das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente (nesse caso por intermédio de pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede no País), a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão

obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.

Dessa forma, como anotou o então Senador Romeu Tuma na complementação do Parecer n. 242/2002 da CCJ (*análise da emenda de redação n. 3*), pela regra estão “... abrangidos o volume de ações com direito a voto (ordinárias) e o volume de ações sem direito a voto (preferenciais)”.²¹

A **participação de capital estrangeiro**, de acordo com o art. 222, § 4.º, da CF/88, será disciplinada por **lei**. Conferindo eficácia a esse dispositivo constitucional, o art. 2.º, *caput*, da Lei n. 10.610, de 20.12.2002 (*fruto da conversão da MP n. 70/2002* e conhecida como *Lei do Capital Estrangeiro*), estabeleceu que a participação de estrangeiros ou de brasileiros naturalizados há menos de dez anos no capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão **não poderá exceder a 30% do capital total** e do **capital votante** dessas empresas, e somente ocorrerá de **forma indireta**, por intermédio de pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede no País.

Nesse contexto, ao permitir a participação das pessoas jurídicas no capital social, inclusive de capital estrangeiro, dentro dos limites fixados, a nova regra, rompendo com a estrutura familiar reinante, atende às necessidades de **capitalização das empresas**, especialmente no atual momento de crise do setor, que necessita, cada vez mais, de investimentos expressivos em tecnologias altamente sofisticadas (por exemplo, a *TV digital*).

Garantindo a proposta de **“alteração controlada”** e a **cultura nacional**, o art. 222, § 2.º, determina que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social, sendo nulo de pleno direito, nos termos do art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 10.610/2002, qualquer acordo, ato, contrato ou outra forma de avença que, direta ou indiretamente, de direito ou de fato, atente contra a regra constitucional.

De acordo com o art. 222, § 3.º, os **meios de comunicação social eletrônica** (radiodifusão sonora e de sons e imagens), independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios

enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.

Nessa política, toda alteração de controle acionário das empresas (ver art. 222, § 1.º) deverá ser comunicada ao **Congresso Nacional**. O parágrafo único do art. 3.º da Lei n. 10.610/2002 dispõe que a comunicação ao Congresso Nacional de alteração de controle societário de empresas de radiodifusão será de responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo, e a comunicação de alterações de controle societário de empresas jornalísticas será de responsabilidade dessas empresas.

■ **19.7.4. Serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (TV)**

■ **19.7.4.1. Diferenciação entre os serviços de telecomunicação e de radiodifusão (EC n. 8/95)**

Não se pode imaginar um país sem avanços no campo da telecomunicação, a qual, para evitar o caos, precisa de regramento, seja no plano interno, seja no internacional.

Nos termos do art. 4.º do *Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT)*, aprovado pela Lei n. 4.117, de 27 de agosto de 1962, constituem **serviços de telecomunicações** a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Telegrafia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão de escritos, pelo uso de um código de sinais. Telefonia, por sua vez, é o processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra falada ou de sons.

A redação original da CF/88, em seu art. 21, XI e XII, “a”, dava tratamento idêntico aos serviços de **telecomunicação** e de **radiodifusão**, estes últimos considerados espécies do gênero telecomunicação.

A **EC n. 8/95**, objetivando a privatização dos serviços de telefonia e

transmissão de dados, então explorados pela *TELEBRÁS* e pela *EMBRATEL*, alterou a redação dada aos incisos XI e XII, “a”, do art. 21, diferenciando os serviços de **telecomunicação** dos de **radiodifusão**.

REDAÇÃO ORIGINAL DO TEXTO DE 1988	REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC N. 8/95
Art. 21. Compete à União:	Art. 21. Compete à União:
XI — explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal , os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações explorada pela União;	XI — explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão , os serviços de telecomunicações , nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII — explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações;	XII — explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;

Em razão da nova regra, foi editada a Lei n. 9.472/97 (*Lei Geral de Telecomunicações — LGT*), que dispõe sobre a organização dos serviços de **telecomunicações** e a criação e funcionamento de um órgão regulador, a Agência Nacional de Telecomunicações (**ANATEL**).

Por sua vez, os serviços de **radiodifusão** continuam sob a administração do Poder Executivo (*Ministério das Comunicações*) e regulados pela Lei n. 4.117/62 (*Código Brasileiro de Telecomunicações — CBT*).²²

Nos termos do art. 6.º, “d”, do *CBT*, os serviços de radiodifusão, destinados

a serem recebidos *direta e livremente* (e também gratuitamente) pelo público em geral, compreendem os de **radiodifusão sonora (rádio)** e de **sons e imagens (TV)**.²³ Trata-se da denominada “comunicação eletrônica”, que deve ter finalidade educativa, artística, cultural e informativa, sendo considerada de interesse nacional.

Por fim, destacamos o *Decreto n. 5.820/2006*, que dispõe sobre a implantação do SBTVD-T,²⁴ estabelece diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, entre outras providências.

O período de transição do sistema de transmissão analógica para o digital foi fixado, nos termos do art. 10 do referido decreto, em **10 anos**, contados a partir de sua publicação (*DOU* de 30.06.2006).

■ 19.7.4.2. **Concessão, permissão e autorização**

O art. 223, *caput*, reforça a regra fixada no art. 21, XII, “a”, e estabelece, conforme já visto, que cabe ao Poder Executivo **outorgar** e **renovar concessão, permissão e autorização** para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens (TV), observado o **princípio da complementaridade** dos sistemas privado, público e estatal.

A outorga para a prestação dos serviços de radiodifusão poderá ser estabelecida em caráter **comercial, educativo** ou **comunitário** (neste caso atendendo somente determinada comunidade de bairro e/ou vila).

Conforme ressalta José Afonso da Silva, “... no caso da **concessão**, o ato de outorga e de sua renovação se efetiva por meio de um *contrato administrativo*, pelo qual o serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral, é delegado pelo Presidente da República em nome da União (concedente) a uma pessoa jurídica (concessionária), que o executará em seu próprio nome, por sua conta e risco, por prazo determinado. A **permissão**, que também se realiza por um contrato de natureza precária, é o meio pelo qual

o Presidente da República outorga a uma pessoa física ou jurídica o serviço de radiodifusão limitado ao serviço de radioamador (...) e que não visem a qualquer objetivo pecuniário ou comercial (...). A **autorização** também é ato unilateral e precário pelo qual o Presidente da República outorga os serviços de radiodifusão de caráter local. As concessões, permissões e autorizações não têm caráter de exclusividade e se restringem, quando envolvem a utilização de radiofrequência, ao respectivo uso, sem limitação do direito, que assiste à União, de executar diretamente serviço idêntico”.[25](#)

■ 19.7.4.3. *Prazo da concessão ou permissão e da autorização*

O prazo da **concessão** ou **permissão** será de **10 anos** para as emissoras de **rádio** e de **15 anos** para as de **televisão**, podendo ser renovado por igual período e desde que cumpridos os preceitos fixados nas leis do setor (art. 223, § 5.º).

A **autorização**, por seu turno, na medida em que se trata de ato unilateral e precário, não se submete a prazo, podendo ser cancelada unilateralmente e a qualquer tempo.

■ 19.7.4.4. *Outorga e renovação (da concessão ou permissão e da autorização)*

Como vimos, o ato de outorga (inicial) ou renovação (para quem já é titular) de *concessão*, *permissão* ou *autorização* para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens é de competência do **Poder Executivo**.

■ **Concessão ou permissão:** para a outorga, verifica-se tanto um *controle prévio*, já que o ato de outorga pelo Presidente da República dependerá de anterior escolha por meio de procedimento licitatório, como, ainda, um *controle posterior e sucessivo*, pelo Congresso Nacional (art. 223, §§ 1.º a 5.º).[26](#)

Assim, para a concessão ou permissão, o Congresso Nacional apreciará o ato

no prazo do art. 64, §§ 2.º e 4.º, a contar do recebimento da mensagem, uma vez que o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.

O titular de contrato administrativo de concessão ou permissão tem direito à renovação. Trata-se de **direito condicionado**, visto que, consoante o art. 67, parágrafo único, da Lei n. 4.117/62, o direito à renovação decorre do cumprimento pela empresa de seu contrato de **concessão** ou **permissão**, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência.

A garantia do direito à renovação materializa-se no art. 223, § 2.º, ao estabelecer que a *não renovação* da **concessão** ou **permissão** dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal.

Reforçando as garantias, o cancelamento da **concessão** ou **permissão**, antes do vencimento do prazo, dependerá de **decisão judicial**, assegurando, assim, a liberdade de imprensa e evitando, por consequência, perseguição ou pressão políticas.

■ **Autorização:** na medida em que o art. 223, § 3.º, não se refere ao ato de autorização, segundo argumenta José Afonso da Silva, a sua outorga, “... dado seu caráter precário e seu objeto de pequena monta”, não está sujeita ao controle pelo Congresso Nacional. Tanto é assim, que, conforme visto, a autorização, por ser ato unilateral e precário, não se submete a prazo, podendo ser cassada a qualquer momento.

Nesse sentido, o STF, ao analisar pedido de autorização para a distribuição de sinal de televisão por cabo (TV a cabo), entendeu que a **autorização** (veja, não é concessão nem permissão) é ato precário e, assim, está sujeita à discricionariedade da Administração Pública: “Pedido de autorização para operar distribuição de sinais de televisão a cabo. Supremacia do interesse público sobre o privado. **Autorização**. Ato de **natureza precária**. Necessidade de preenchimento de requisitos objetivos e **subjetivos (conveniência e**

oportunidade). Ausência de direito subjetivo da recorrente” (RMS 22.665, Rel. p/ o acórdão Min. Nelson Jobim, j. 14.03.2006, DJ de 04.08.2006).

■ **19.7.4.5. Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T): consignação de mais um canal de radiofrequência às concessionárias e “autorizadas” dos serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens, sem apreciação do Congresso Nacional**

O Decreto n. 5.820/2006 dispôs sobre a implantação do **Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre — SBTVD-T**, além de estabelecer diretrizes para a **transição** do sistema de transmissão **analógica** para o sistema de transmissão **digital** do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão.

Questão polêmica surgiu em razão de haver o Presidente da República consignado mais um canal para as concessionárias e “autorizadas”, sem o controle político pelo Congresso Nacional, como determina o art. 223 da CF/88 (art. 7.º do Dec. n. 5.820/2006).

O STF, em importante decisão, reconheceu que não haveria nenhuma afronta à Constituição, pois, no caso, não se tratava de nova concessão, mas apenas de uso “dobrado” dos canais para que fosse possível a transição entre os dois sistemas.

Esclareceu o Min. Ayres Britto que, “... diante da evolução tecnológica, e para a instituição no país da tecnologia digital de transmissão de sons e imagens, sem interrupção da transmissão de sinais analógicos, fez-se imprescindível a **consignação temporária** de mais um canal às atuais concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens. Isso para que veiculassem, **simultaneamente**, a **mesma programação** nas tecnologias **analógica** e **digital**. Tratou-se de um ato do Presidente da República com o objetivo de manter um serviço público adequado, tanto no que se refere à sua atualidade quanto no tocante à sua continuidade. Ato por isso mesmo serviente do princípio constitucional da **eficiência** no âmbito da Administração Pública. 5. A televisão digital, comparativamente com a TV analógica, não consiste em novo serviço

público. Cuida-se da mesma transmissão de sons e imagens por meio de ondas radioelétricas. Transmissão que passa a ser digitalizada e a comportar **avanços tecnológicos**, mas sem perda de identidade jurídica. **Os dispositivos impugnados na ação direta não autorizam, explícita ou implicitamente, o uso de canais complementares ou adicionais para a prática da multiprogramação, pois objetivam, em verdade, ‘permitir a transição para a tecnologia digital sem interrupção da transmissão de sinais analógicos’** (*caput* do art. 7.º do Decreto 5.820/2006)”.[27](#)

■ 19.7.5. Conselho de Comunicação Social: órgão auxiliar do CN

O art. 224, decorrente do art. 403 do *Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos*, estabeleceu que o Congresso Nacional instituiria, como **órgão auxiliar** das questões referentes à **comunicação social**, e na forma da lei, o **Conselho de Comunicação Social**.

Regulamentando o art. 224, a Lei n. 8.389, de 30.12.1991, fixou que o Conselho seria eleito em até 60 dias após a sua publicação e instalado em até 30 dias após a eleição do referido Conselho.

Com atraso de mais de 10 anos, em 05.06.2002, foram eleitos os 13 membros do Conselho (8 representantes ligados à comunicação social e 5 da sociedade civil — ver art. 4.º da lei), órgão não deliberativo, que tem a atribuição de **auxiliar o Congresso Nacional**, realizando estudos, pareceres e outras recomendações que lhe forem encaminhadas sobre as matérias relacionadas à comunicação social, buscando, por consequência, garantir o cumprimento da **função social** de toda empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

■ 19.7.6. Direito de antena

A previsão da comunicação social, sem dúvida, assegura o denominado **direito de antena**.

Segundo Bulos, na **Espanha** e na **Alemanha** o direito de antena seria a prerrogativa que as empresas de comunicação têm para poder funcionar e difundir a comunicação. Em **Portugal**, é o direito de resposta e réplica política. “No **Brasil**, *direito de antena* é a possibilidade de captar ou transmitir informações por meio de ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Por meio de ondas mecânicas, a comunicação se propaga diretamente pelo ar, como no caso dos alto-falantes, colocados nos locais de uso comum do povo (praças, bairros e centros comunitários etc.). Já por intermédio das ondas eletromagnéticas, o ato de comunicar adquire dimensões elevadas, pois ocorre a junção de um componente elétrico com outro magnético, conduzindo muita informação ao mesmo tempo (rádios, televisões). A Constituição de 1988 consagrou normas relacionadas diretamente ao *direito de antena*”. [28](#)

Assim, exemplificando, o direito assegurado aos partidos políticos de **acesso gratuito ao rádio e à televisão** (art. 17, § 3.º) pode ser qualificado como uma das facetas do direito de antena, não importando o tamanho do partido político, seja grande ou pequeno, e, dessa forma, assegurando, como **direito público subjetivo das minorias**, o direito dos denominados *partidos nanicos*, tendo o STF declarado inconstitucional a cláusula de barreira instituída na *Lei dos Partidos Políticos*, bem como a exigência, para o rateio, de se ter representação na Câmara dos Deputados (Lei n. 9.096/95 — cf. *item 18.3*).

■ 19.7.7. Lei de Imprensa — ADPF 130

Cabe anotar que, no julgamento da **ADPF 130**, por maioria, em 30.04.2009, o STF declarou que a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) é incompatível com a atual ordem constitucional, tendo, portanto, sido **revogada** pelo novo ordenamento. Nesse sentido:

“A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a

mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5.º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5.º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado ‘poder social da imprensa’” (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, j. 30.04.2009, Plenário, *DJE* de 06.11.2009).

■ 19.7.8. “Lei Eleitoral sobre o Humor”

O art. 45, II e III, da Lei n. 9.504/97 (*Lei das Eleições*) estabeleceu que, a partir de 1.º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário:

- usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;
- veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.

O § 4.º do art. 45, introduzido pela Lei n. 12.034/2009, conceitua **trucagem** como “todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação”.

Por sua vez, o § 5.º do mesmo artigo, também introduzido pela Lei n. 12.034/2009, estatui que a **montagem** é “toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou

coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação”.

A questão foi posta no STF na **ADI 4.451**. Em 02.09.2010, a Corte entendeu, referendando a liminar do Min. Ayres Britto, que o art. 45, II e III, e §§ 4.º e 5.º violam a **liberdade de imprensa**, já que o **humor** pode ser considerado **imprensa**.

Referidos dispositivos afrontam, também, a **plena liberdade de informação jornalística**, nos termos do **art. 220, § 1.º**, da CF/88. Ainda, a manifestação, mesmo que seja pelo humor, não pode ser restringida, já que instrumentaliza e permite o **direito de crítica** e de **opinião**.

Naturalmente, eventual abuso poderá ser reparado pelo Judiciário por caracterizar os crimes de calúnia, injúria ou difamação, à luz do Código Penal (**mérito da matéria pendente de julgamento pelo STF**).

■ 19.8. MEIO AMBIENTE

■ 19.8.1. Conceito de meio ambiente

Alguns autores chegam a criticar a expressão “meio ambiente”, alegando suposta redundância, uma vez que a expressão “meio” já estaria englobada pela palavra “ambiente”; portanto, seriam sinônimas. [29](#)

Contudo, observa José Afonso da Silva que “... a expressão *meio ambiente* se manifesta mais rica de sentido (como conexão de valores) do que a simples palavra *ambiente*. Esta exprime o conjunto de elementos; aquela expressa o resultado da interação desses elementos. O *conceito de meio ambiente* há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico”.

E conclui: “O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos

naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais”.[30](#)

Cabe salientar, ainda, que o **preservacionismo ambiental** caracteriza-se como direito humano de **terceira dimensão**, estando o ser humano inserido na coletividade e, assim, titular dos direitos de **solidariedade**.

■ 19.8.2. Aspectos do meio ambiente

Conforme proposto, reconhecendo o **caráter unitário** do conceito de meio ambiente, do ponto de vista didático, propomos a identificação de quatro importantes aspectos, focando aspectos específicos:

■ **Meio ambiente natural ou físico:** nos termos do art. 3.º, I, da Lei n. 6.938/81 (que dispõe sobre a *Política Nacional do Meio Ambiente*), pode ser definido como *o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas*. Em outras palavras, o meio ambiente natural ou físico é constituído pelo solo, água, ar atmosférico, energia, flora, fauna, ou seja, a correlação entre os seres vivos e o meio em que vivem (cf. art. 225, *caput*, e § 1.º, I e VII).

■ **Meio ambiente cultural:** aponta a história e a cultura de um povo, as suas raízes e identidade, sendo integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico (cf. arts. 225, *caput*, 215 e 216).

■ **Meio ambiente artificial ou humano:** materializa-se no espaço urbano construído, destacando-se as edificações (*espaço urbano fechado*) e também os equipamentos públicos, como as ruas, espaços livres, parques, áreas verdes, praças etc. (*espaço urbano aberto*) (cf., entre outros, os arts. 225, *caput*, 5.º, XXIII, 182 e s. etc.).

■ **Meio ambiente do trabalho:** espécie do meio ambiente artificial, ganha destaque, e, tratado em categoria autônoma, caracteriza-se como o local em que o trabalhador exerce a sua atividade. Nos termos do art. 200,

VIII, é atribuição do Sistema Único de Saúde a colaboração com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Assim, a proteção encontra fundamento também nos direitos ligados à saúde, uma vez que é indispensável que se garantam aos trabalhadores condições de salubridade e segurança (cf. arts. 196 e s. e 7.º da CF/88).

■ 19.8.3. Direitos humanos, direito ao desenvolvimento e direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações

■ 19.8.3.1. A problemática

Fazendo um resgate histórico, encontramos certa preocupação com o meio ambiente desde o **direito romano**, em especial quanto à limpeza das águas, ao barulho, à fumaça e à preservação de áreas plantadas.

É pertinente afirmar, contudo, que essa preocupação se restringia a questões de **direito imobiliário**, intrinsecamente atreladas a uma perspectiva **econômica**.

As modernas noções de preservacionismo ambiental, direito ambiental, bem como a sua necessária conscientização, surgem em meados do século XX, sob outra perspectiva.

Segundo Guido Fernando Silva Soares,³¹ a consciência da necessidade de proteção do meio ambiente decorre:

- dos problemas advindos com o crescimento caótico das atividades industriais;
- do consumismo desenfreado em âmbito local e mundial;
- de uma filosofia imediatista pelo desenvolvimento a qualquer preço;
- da inexistência de uma preocupação inicial com as repercussões causadas ao meio ambiente pela atividade econômica;
- da assunção de que os recursos naturais seriam infinitos, inesgotáveis e recicláveis por mecanismos automáticos incorporados à natureza (meados do século XIX) — Revolução Industrial.

Surge, então, a temática da inter-relação entre o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento.

O argumento falacioso e político, expressado pelos países desenvolvidos, “sugerindo” que os países em desenvolvimento diminuam as atividades potencialmente degradantes ao meio ambiente para se tornarem santuários da humanidade, deve ser afastado. É o que passamos a estudar.

Tentaremos estabelecer um equilíbrio entre os **direitos humanos**, o **direito ao desenvolvimento** e o **direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado** para as presentes e futuras gerações. [32](#)

Isso porque, consoante o art. 1.º da *Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas*, adotada pela Res. n. 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 04.12.1986, o direito ao desenvolvimento é um *direito inalienável* de toda pessoa humana e de todos os povos, em virtude do qual estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, garantindo-se a plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. [33](#)

Conclui-se, então, que o direito ao desenvolvimento deve observar a questão ambiental. A CF/88 (art. 170, *caput*, e VI) estabelece que a **ordem econômica**, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, o da **defesa do meio ambiente**, inclusive mediante tratamento diferenciado de acordo com o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Nesse contexto, o art. 4.º, I, da Lei n. 6.938/81 já havia previsto que a *Política Nacional do Meio Ambiente* visará à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

■ 19.8.3.2. **Sustentabilidade: solução para a problemática**

A **sustentabilidade** apresenta-se como a chave mestra para a solução desse aparente conflito de valores constitucionalizados, seja mediante a garantia do direito ao desenvolvimento, seja prestigiando a preservação do ser humano e seus direitos fundamentais. [34](#)

Com precisão, observa Édis Milaré: “É por isso que hoje se fala com tanta insistência em **desenvolvimento sustentado ou ecodesenvolvimento**, cuja característica consiste na possível conciliação entre o **desenvolvimento**, a **preservação ecológica** e a **melhoria da qualidade de vida do homem**. É falso o dilema ‘ou desenvolvimento ou meio ambiente’, na medida em que, sendo uma fonte de recursos para o outro, devem harmonizar-se e complementar-se. Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico dentro de uma dimensão tempo/espço. Em outras palavras, isto significa dizer que a política ambiental não deve constituir em obstáculo ao desenvolvimento...”. [35](#)

Ressaltamos, então, a regra do art. 225, *caput*, da CF/88: **todos** têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eis aqui a consagração do **desenvolvimento sustentável**.

■ 19.8.4. A proteção ambiental no constitucionalismo brasileiro

A análise do constitucionalismo brasileiro nos permite afirmar que foi somente no texto de 1988 que se estabeleceu, de maneira específica e global, a proteção ao meio ambiente.

Na lição de Milaré, “a) desde a Constituição de 1934, todas mantiveram a proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico do país; b) houve constante indicação no texto constitucional da *função social da propriedade*

(1934, art. 115; 1946, arts. 147 e 148; 1967, art. 157, III, e § 8.º; 1969, arts. 160, III, e 163), solução que não tinha em mira — ou era insuficiente para — proteger efetivamente o patrimônio ambiental; c) jamais se preocupou o legislador constitucional em proteger o meio ambiente de forma específica e global, mas, sim, dele cuidou de maneira diluída e mesmo casual, referindo-se separadamente a alguns de seus elementos integrantes (florestas, caça, pesca), ou então disciplinando matérias com ele indiretamente relacionadas (mortalidade infantil, saúde, propriedade)”.[36](#)

■ **Constituição de 1824:** estabeleceu a proibição de trabalho, cultura, indústria ou comércio que se opusessem à segurança e saúde dos cidadãos (art. 179, XXIV).

■ **Constituição de 1891:** competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre terras e minas de propriedade da União (art. 34, n. 29).

■ **Constituição de 1934:** fixou a competência concorrente entre União e Estados para proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte (arts. 10, III, e 148). Previu, ainda, ser competência privativa da União legislar sobre bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração (art. 5.º, XIX, “j”).

■ **Constituição de 1937:** nos termos do art. 134, os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Fixou, ainda, ser competência privativa da União legislar sobre os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua exploração (art. 16, XIV), podendo os Estados legislar, respeitadas as regras da lei federal, sobre questões específicas (art. 18, “a”).

■ **Constituição de 1946:** nos termos do art. 175, as obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos

naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza, estavam sob a proteção do Poder Público. Manteve a competência da União para legislar sobre as riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, floresta, caça e pesca (art. 5.º, XV, “f”).

■ **Constituição de 1967:** nos termos do art. 172, tendo fixado o amparo à cultura como dever do Estado, estavam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. Foi mantida a competência da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; florestas, caça e pesca (art. 8.º, XVII, “h”).

■ **EC n. 1/69 (alterando a Constituição de 1967):** manteve a linha do texto emendado, utilizando pela primeira vez o vocábulo “ecológico”. [37](#)

■ **Constituição de 1988:** foi o primeiro texto a trazer, de modo específico e global, inclusive em capítulo próprio, regras sobre o meio ambiente, além de outras garantias previstas de modo esparsa na Constituição, destacando-se os seguintes artigos: 5.º, LXXIII (*instrumento de tutela ambiental*); 20, II a XI, e § 1.º (*bens da União*); 23, I, II, III, IV, VI, VII, IX e XI (*competência administrativa, comum, cumulativa ou paralela, atribuída em relação aos quatro entes federativos: União, Estados, DF e Municípios*); 24, VI, VII, VIII e XII (*competência legislativa concorrente*); 26, I, II e III (*bens dos Estados*); 30, VIII e IX (*competência privativa enumerada*); 91, § 1.º, III (*atribuição do Conselho Nacional de Defesa*); 129, III (*função institucional do MP para a promoção do inquérito civil e o ajuizamento da ACP*); 170, VI (*princípio da ordem econômica*); 174, § 3.º (*organização da atividade garimpeira e cooperativas*); 176, § 1.º (*recursos minerais e potenciais de energia hidráulica*); 186, II (*função social da propriedade rural*); 200, VIII (*meio ambiente do trabalho*); 216, V (*patrimônio cultural brasileiro*); 220, § 3.º, II (*comunicação social e proteção ambiental*); 225 (*proteção, de modo específico e global, do meio ambiente*), 231, §§ 1.º e 3.º (*índios*) etc.

■ 19.8.5. Natureza jurídica do meio ambiente e a justiça distributiva entre as presentes e futuras gerações

O art. 225, *caput*, preceitua que **todos** têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao **Poder Público** e à **coletividade** o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O dever de preservação será por parte do Estado e da coletividade, uma vez que o meio ambiente não é um bem privado ou público, mas **bem de uso comum do povo**.

Podemos sustentar que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa e, assim, caracterizado como *res omnium — coisa de todos*, e não como *res nullius*, como advertiu Sérgio Ferraz.³⁸ Trata-se de direito que, apesar de pertencer a cada indivíduo, é de todos ao mesmo tempo e, ainda, das futuras gerações.

Como corretamente nota Cristiane Derani,³⁹ o texto de 1988 inova ao estabelecer uma **justiça distributiva entre as gerações** (ou **redistribuição** entre as gerações), visto que as gerações do presente não poderão utilizar o meio ambiente sem pensar no futuro das gerações posteriores, bem como na sua sadia qualidade de vida, intimamente ligada à preservação ambiental.

■ 19.8.6. Incumbência do Poder Público

Para assegurar a efetividade do direito a um **meio ambiente ecologicamente equilibrado** para as presentes e futuras gerações, incumbe ao Poder Público (art. 225, § 1.º, I a VII):

- **Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais:** processos vitais para a manutenção dos ecossistemas.
- **Prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.**
- **Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País.**

■ **Fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético.**

■ **Espaços territoriais especialmente protegidos:** definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de **lei**,⁴⁰ vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. O art. 225, § 4.º, estabelece alguns espaços territoriais e os qualifica como patrimônio nacional.

■ **EIA/RIMA:** exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. O estudo de impacto ambiental (*EIA*) será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, que apresentará um relatório de impacto ambiental (*RIMA*) (cf. Res. CONAMA⁴¹ n. 1/86).⁴²

■ **Controle estatal:** controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

■ **Educação ambiental:** promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

■ **Fauna e flora:** proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

■ 19.8.7. Crueldade contra animais?

COLISÃO	
■ Proteção da manifestação cultural	■ Proibição de tratamento cruel aos animais

Importante tema que se coloca refere-se à suposta colisão entre a proteção da manifestação cultural (art. 215, *caput*, e § 1.º) e a proibição de tratamento cruel aos animais (art. 225, § 1.º, VII). Abordaremos, então, quatro interessantes questões: **a)** farra do boi; **b)** rinhas ou brigas de galos; **c)** rodeios de animais; **d)** animais em circo.

■ 19.8.7.1. Farra do boi

A **farra do boi** pode ser caracterizada como um antigo costume ibérico, transportado para o arquipélago de Açores e trazido para o Estado de Santa Catarina, no Brasil (Florianópolis e todo o litoral), por imigrantes daquela região.

Chegou a ter inspiração religiosa, normalmente praticada durante a quaresma e culminando na Páscoa, aparecendo o boi como protagonista em encenações sobre a *Paixão de Cristo*. A “farra do boi” já foi vista também como entretenimento, alegando alguns uma suposta tradição cultural. O boi fica sem comer por dias e depois é solto e perseguido nas ruas da cidade. Existem relatos de maus-tratos contra os animais.

O STF entendeu **inconstitucional** a “farra do boi”, pois a crueldade praticada contra os animais não teria como fazer prevalecer uma suposta tradição cultural.

‘EMENTA: Costume — Manifestação cultural — Estímulo — Razoabilidade — Preservação da fauna e da flora — Animais — Crueldade. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que **veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade**. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado “farra do boi” (RE 153.531, Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, j. 03.06.97, DJ de 13.03.98 — grifo

nosso).

■ 19.8.7.2. *Rinhas ou brigas de galo*

As **rinhas** ou **brigas de galo** podem ser conceituadas como a realização de atividades denominadas “esportivas”, em recintos próprios e fechados (*rinhadeiros*). Aves das *raças combatentes* são colocadas para se enfrentar.

Também quanto a essas manifestações, entendeu o STF que se tratava de violação ao art. 225, § 1.º, VII, por submeter os animais a crueldade.

“EMENTA: Inconstitucionalidade. Ação direta. Lei n. 7.380/98, do Estado do Rio Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das raças combatentes. ‘Rinhas’ ou ‘Brigas de galo’. Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio ambiente. Animais. **Submissão a tratamento cruel**. Ofensa ao art. 225, § 1.º, VII, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que autorize e regulamente, sob título de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas combatentes, as chamadas ‘rinhas’ ou ‘brigas de galo’” (ADI 3.776, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.06.2007, *DJ* de 29.06.2007).[43](#)

■ 19.8.7.3. *Rodeios de animais, vaquejada, “calf roping” e “team roping” (laçada dupla)*

Nos termos do art. 1.º, parágrafo único, da Lei n. 10.519/2002, “consideram-se **rodeios** de animais as atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliados a habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal”.

Enfrentando outros temas, o Des. Castilho Barbosa, do TJ/SP, explicou: “**vaquejada** — quando peões seguram fortemente o animal pela cauda para ser contido na fuga; **calf roping** — bezerros, com quarenta dias de vida, são tracionados no sentido contrário em que correm, erguidos e lançados violentamente ao solo, em prática que além de causar lesões pode levá-los à morte, e **team roping** ou **laçada dupla** — prática em que um peão laça a cabeça de um garrote, enquanto outro laça as pernas traseiras, na sequência o

animal é esticado, ocasionando danos na coluna vertebral e lesões orgânicas” (AGRV 419.225.5/5, de 30.01.2007).

Nesse sentido, as atividades vêm sendo permitidas, desde que não configurem crueldade aos animais.

‘EMENTA: Agravo de Instrumento — Interposição contra decisão proferida em Primeiro Grau e que deferiu medida liminar em ação civil pública — Inconformismo — Admissibilidade em parte — Possibilidade da realização do rodeio e, nele, da ‘montaria’; proibida, no entanto, a utilização de sedém, peiteiros, choques elétricos ou mecânicos e esporas; e as práticas de ‘Vaquejada’, ‘calf roping’ e ‘team roping’ — Entendimento jurisprudencial sobre o tema — Recurso parcialmente provido, sem prejuízo de eventual perda do objeto do presente agravo” (AGRV 419.225.5/5, de 30.01.2007).

A grande questão que se coloca, portanto, é a prática **de maus-tratos e crueldade** contra os animais. Desde que não haja atos de **flagelação** aos animais, as festas de rodeio e de peão vêm sendo admitidas pelos Judiciários locais.

O **STF** ainda não enfrentou a questão específica sobre os **rodeios**, estando pendente de julgamento a **ADI 3.595**, ajuizada pelo Governador de São Paulo com pedido de liminar, contra o *Código de Proteção aos Animais do Estado* (Lei estadual n. 11.977/2005), que, entre outros pontos, proibiu, nesse Estado, as provas de rodeio e de espetáculos que envolvam o uso de instrumentos que induzam o animal a se comportar de forma não natural (**Matéria pendente de julgamento pelo STF**).

A **Lei n. 10.519/2002** traz regras sobre a realização de rodeios, buscando evitar apetrechos técnicos utilizados nas montarias que impliquem crueldade aos animais. Já a **Lei n. 10.220/2001** institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional.

Por sua vez, o art. 32 da **Lei n. 9.605/98** (*que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências*), considera crime, a que se comina pena de detenção, de três meses a um ano, e multa, praticar ato de abuso, maus-tratos,

ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Finalmente registramos, e aqui deixamos o nosso abraço para os amigos da região, que a **Lei n. 12.489/2011** confere ao Município de Barretos, no Estado de São Paulo, o título de **Capital Nacional do Rodeio**.

■ 19.8.7.4. *Animais em circo*

■ 19.8.7.4.1. *A origem do circo — breve nota*[44](#)

Muito se discute sobre a origem do circo ou, melhor dizendo, da **arte circense**, chegando alguns a apontar as suas raízes na Grécia antiga ou até mesmo no Egito, servindo o espetáculo para marcar a volta da guerra e, assim, trazendo animais exóticos para demonstrar a grandiosidade das batalhas e a distância percorrida pelos generais.

Outros atribuem o surgimento do circo à China, destacando-se as acrobacias humanas.

Lembramos, ainda, o desenvolvimento da arte circense no Império Romano, como o *Circo Máximo de Roma* e o *Coliseu*.

A ideia do circo moderno, com o picadeiro, a cobertura de lona, as arquibancadas, deve-se a *Philip Astley*, da Inglaterra.

No Brasil, há alguns registros de surgimento do circo no final do século XVIII e da ideia de circo moderno no século XIX, incentivado pelo desenvolvimento econômico, posteriormente.

Hoje se fala em um **“circo contemporâneo”**, ou o **“novo circo”**, enaltecendo a figura do homem e **excluindo a participação de animais**.

■ 19.8.7.4.2. *O adestramento de animais em circos*

No tocante aos animais, muito se discute sobre eventual crueldade.

Como anotou o *Deputado Federal Antônio Carlos Biffi* em seu parecer, “para realizar tarefas como dançar, andar de bicicleta, tocar instrumentos, pular em argolas (com ou sem fogo), cumprimentar a plateia, entre outras proezas, os animais são submetidos a treinamento que, regularmente, envolve chicotadas, choques elétricos, chapas quentes, correntes e outros meios que os violentam. A alimentação e o descanso desses animais são, muitas vezes, inadequados e insuficientes. Há ainda uma perversidade adicional gerada pela presença de carnívoros nos espetáculos circenses — é comum que cães e gatos vivos sejam fornecidos a eles como alimentação, muitas vezes trocados por ingressos pelos moradores da localidade onde se encontra o circo”.[45](#)

Segundo relata o *Deputado Federal Jorge Pinheiro*, ao analisar o **PL n. 7.291/2006**, que tramita na CD, “vários circos famosos internacionalmente — como o *Circo Soleil* do Canadá e o *Circo Oz* da Austrália — **não utilizam animais em seus espetáculos** e, inclusive, a *Escola Nacional de Circos* se manifestou a favor do projeto de lei proibindo animais em circos no Estado do Rio de Janeiro. No Brasil, o *Circo Popular do Brasil*, além de outros cinco circos, apresentam apenas espetáculos com humanos. A apresentação de animais nos espetáculos circenses em nada contribui à educação ambiental da população, visto que o comportamento apresentado não se assemelha ao comportamento natural desses animais, inclusive expondo-os ao ridículo. Mesmo alguns empresários de circo reconhecem que há uma tendência mundial de desvalorização de animais como atração circense e que o ‘circo do futuro’ valorizará mais o artista”.[46](#)

■ **19.8.7.4.3. O fim dos animais em circos significaria o fim da cultura circense?**

Por todo o exposto, não nos parece que o uso de animais seja essencial para que o circo cumpra o seu relevante papel para a cultura de nosso país.

Em um primeiro momento, a utilização dos animais nos circos tenderia mais a caracterizar a crueldade do que o fortalecimento da cultura.

Muitos incidentes com animais de circos já foram relatados. Há notícias de maus-tratos e abandono de animais, bem como de tragédias, como, em 09.04.2000, a morte de um menino de 6 anos por leões do *Circo Vostok* em Jaboatão dos Guararapes/PE, levando a sociedade a se revoltar e ao encaminhamento de projetos de lei no sentido de proibir a utilização de animais nos circos.

Alguns Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, assim como vários Municípios, já proibiram a participação de animais em espetáculos circenses.

Proibir a utilização de animais em circo não significará o fim da arte, da cultura circense, que tem muito a oferecer, como a apresentação dos malabaristas, dos trapezistas, dos engolidores de fogo, dos mágicos, dos palhaços e de tantos, homens e mulheres, artistas que fazem da arte a sua vida e lutam para encantar, alegrar e estimular o sonho e o imaginário.

Assim, preserva-se a cultura, e, ao mesmo tempo, ao não se admitir o emprego de animais em circos, garante-se a proibição de crueldade, harmonizando os preceitos constitucionais.

■ 19.8.8. Importação de pneus usados — ADPF 101

O STF, julgando a **ADPF 101**, declarou que a legislação que **proíbe** a importação de pneus usados é **constitucional** (cf. *Inf.* 538 e 552/STF).

Os fundamentos utilizados pela Suprema Corte foram:

- proteção à saúde;
- meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- soberania nacional;
- defesa do meio ambiente;
- princípios internacionais decorrentes de tratados de proteção ambiental.

■ 19.8.9. Exploração de recursos minerais

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

Conforme anota Paulo Affonso Leme Machado, “foi um avanço considerável — e a nível da maior lei do país — considerar indubitavelmente a atividade minerária ou a mineração como atividade degradadora do ambiente pelo só fato dessa atividade existir. Há, contudo, três formas de degradação diferentes que podem advir da mineração: a **primeira**, poderá ser evitada antes do licenciamento da lavra e/ou da pesquisa, através do estudo de impacto ambiental; a **segunda**, poderá ser combatida durante o funcionamento da atividade de lavra e/ou pesquisa; e a **terceira**, a de que cuida a Constituição: a **recomposição**. A norma constitucional não eliminou as duas fases apontadas, mas mostrou que toda atividade de mineração importa em necessidade de uma atividade de recuperação”.⁴⁷

A exploração, ainda nos termos do art. 225, *caput*, terá de ser **sustentável** para evitar o esgotamento dos recursos minerais, inclusive para as gerações futuras.

■ 19.8.10. Responsabilidade por danos ambientais

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas **físicas** ou **jurídicas**, a sanções **penais** e **administrativas**, independentemente da obrigação de **reparar os danos causados** (art. 225, § 3.º).

■ **Responsabilidade criminal:** influenciado pelo art. 45, § 3.º, da Constituição espanhola, o constituinte de 1988 erigiu o meio ambiente a bem jurídico-penal autônomo, prevendo a responsabilização criminal em razão dos crimes ecológicos. Nesse sentido, o princípio da reserva legal deverá ser respeitado, destacando-se a Lei n. 9.605/98. Outro ponto

bastante interessante foi o estabelecimento de **responsabilidade penal**[48](#) da **pessoa jurídica**.[49](#) e 50

■ **Responsabilidade administrativa:** diante da violação de normas administrativas, foram estabelecidas sanções também de natureza administrativa, como multa, interdição da atividade, advertência, suspensão de benefícios etc.[50](#)

■ **Responsabilidade civil:** todo dano ambiental, de qualquer natureza (contratual, extracontratual, que decorra de ato ilícito ou mesmo lícito), deverá ser indenizado. Trata-se de **responsabilidade objetiva e integral** (cf. art. 21, XXIII, “d”, da CF/88 e art. 14, § 1.º, da Lei n. 6.938/81)[51](#) em razão do **dano ecológico**, independentemente de culpa, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade. Tendo em vista a natureza do dano ambiental, há a preferência pela tutela específica e reposição do *statu quo ante*.[52](#)

■ 19.8.11. Ecossistemas especialmente protegidos e erigidos à categoria de patrimônio nacional

De acordo com o art. 225, § 4.º, são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais:

- Floresta Amazônica brasileira
- Mata Atlântica
- Serra do Mar
- Pantanal Mato-Grossense
- Zona Costeira

Em entendimento fixado pelo STF, “a norma inscrita no art. 225, § 4.º, da Constituição deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo art. 5.º, XXII, da Carta Política, garante e assegura o **direito de propriedade** em todas as suas projeções, inclusive aquela concernente à

compensação financeira devida pelo Poder Público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade estatal”. [53](#)

■ 19.8.12. Os “Soldados da Borracha” e a EC n. 78/2014

De acordo com o art. 54, ADCT, os **seringueiros** recrutados nos termos do Decreto-Lei n. 5.813/43, e amparados pelo Decreto-Lei n. 9.882/46, receberão, **quando carentes**, pensão mensal vitalícia no valor de **2 salários mínimos**.

O benefício [54](#) é estendido aos seringueiros que, atendendo a apelo do governo brasileiro, contribuíram para o **esforço de guerra**, trabalhando na **produção de borracha**, na **Região Amazônica**, durante a **2.ª Guerra Mundial**. Por esse motivo, foram apelidados “**Soldados da Borracha**”.

A **concessão dos benefícios**, que são transferíveis aos dependentes reconhecidamente carentes, está disciplinada na **Lei n. 7.986/89**. De acordo com o seu art. 3.º, na redação dada pela Lei n. 9.711/98, a comprovação da efetiva prestação de serviços, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, **não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal**, vedação essa tida pelo STF como constitucional (**ADI 2.555**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03.04.2003, Plenário, *DJ* de 02.05.2003).

Durante a constituinte, houve muita discussão sobre o tema, pois procura-se dar aos seringueiros um tratamento isonômico em relação aos *ex-combatentes de guerra* que passaram a ter muitos outros direitos e foram, esses últimos, equiparados a 2.º Tenente das Forças Armadas para efeito de pagamento de pensão.

Essa perspectiva, contudo, não foi alcançada. Observa-se um grande distanciamento entre as duas categorias e, assim, iniciou-se outra longa discussão com o objetivo de se “minorar os problemas vividos por aqueles que, com grande sacrifício pessoal, trabalhando sob as mais difíceis condições, deram um esforço gigantesco para a derrota do nazifascismo, garantindo às forças aliadas o fornecimento de uma das mais importantes matérias-primas no esforço de

guerra, a borracha” (Parecer da CCJ, Rel. Sen. Aníbal Diniz).

Nesse contexto, foi aprovada a **EC n. 78/2014** estabelecendo que os seringueiros de que trata o art. 54 do ADCT receberão **indenização**, em **parcela única**, no valor de **R\$ 25.000,00**. Essa indenização somente se estende aos dependentes dos seringueiros que, na data de entrada em vigor da referida emenda constitucional (*exercício financeiro seguinte ao de sua publicação*), detenham a condição de dependentes na forma do § 2.º do art. 54 do ADCT, devendo o valor de R\$ 25.000,00 ser rateado entre os pensionistas na proporção de sua cota-parte na pensão.

■ 19.8.13. Terras devolutas

■ 19.8.13.1. *Classificação dos bens públicos: as terras devolutas enquanto bens dominicais*

No tocante à destinação, os bens públicos podem ser classificados em:

■ **Bens de uso comum do povo ou do domínio público:** destinados à utilização geral e igualitária pelos indivíduos, independem de consentimento individualizado pelo Poder Público para a sua utilização e podem ser assim exemplificados: rios, mares, estradas, ruas e praças. Por regra, a sua utilização é gratuita, mas há exemplo de exigência de contraprestação pelo Poder Público, como no caso dos pedágios nas rodovias (art. 99, I, do CC).

■ **Bens de uso especial ou do patrimônio administrativo:** são aqueles utilizados pela Administração Pública para a execução de serviços públicos e administrativos, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias (art. 99, II, do CC).

■ **Bens dominicais ou do patrimônio disponível:** constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades (art. 99, III, do CC), e **não**

se encontram **afetados** a nenhuma finalidade específica, isto é, não são de uso comum do povo nem de uso especial. Como exemplo, destacamos as **terras devolutas** e todas aquelas que não tenham nenhuma destinação pública específica, os prédios públicos desativados, os terrenos de marinha etc.

Feito esse breve apontamento (que deverá ser aprofundado nos livros de *direito administrativo* — no capítulo sobre *bens públicos*), interessa-nos, dentro da ideia de meio ambiente, analisar a questão particular sobre as **terras devolutas**.

■ 19.8.13.2. *Titularidade*

Na época do Brasil colônia, todas as terras descobertas eram públicas e pertenciam a Portugal, que, por sua vez, trespassou parte delas para os colonizadores, mediante as concessões de sesmarias, que deveriam ser demarcadas e cultivadas, sob pena de *comisso*, ou seja, retorno das terras para a Coroa. Dessa forma, tanto as terras que caíram em *comisso* como as que nunca foram trespassadas e, assim, não fixadas como de domínio privado nem tinham destinação específica no domínio público foram consideradas **devolutas**.

Proclamada a **independência**, as terras devolutas passaram a integrar o patrimônio público do **Império**.

Em seguida, nos termos do art. 64 da Constituição de 1891 (**República**), as terras devolutas foram transferidas para os **Estados-Membros**, ficando com a União somente a porção do território indispensável à defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Alguns Estados, por sua vez, transferiram, ao longo do tempo, parcela das terras devolutas para os seus **Municípios**.

Na Constituição de 1988, parte das terras devolutas que já tinham sido destinadas aos Estados **reverteu ao domínio público federal**, uma vez que (art. 20, II) são bens da **União** as **terras devolutas** indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de

comunicação e à **preservação ambiental**, definidas em lei.

Podemos, assim, afirmar que as terras devolutas, desde a Constituição de 1891, por regra, pertencem aos **Estados-Membros**, excetuando-se aquelas que, conforme visto, são indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei (art. 20, II, c/c o art. 26, IV).

Segundo Hely Lopes Meirelles, **terras devolutas** “... são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo Poder Público, nem destinadas a fins administrativos específicos. São bens públicos patrimoniais ainda não utilizados pelos respectivos proprietários”.⁵⁵

■ 19.8.13.3. *Terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado necessárias à proteção dos ecossistemas naturais — indisponibilidade*

Nos termos dos arts. 100 e 101 do Código Civil, os **bens públicos de uso comum do povo** e os de **uso especial** são **inalienáveis**, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Por sua vez, os **bens públicos dominicais** podem ser **alienados**, observadas as exigências da lei.

Diante do exposto, teoricamente, as terras devolutas, por serem bens públicos dominicais, poderiam ser alienadas.

Contudo, as **terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados** (art. 26, IV), por ações discriminatórias, **necessárias à proteção dos ecossistemas naturais**, foram declaradas **indisponíveis** pela Constituição (art. 225, § 5.º), **não** podendo, portanto, ser **alienadas**. O constituinte, nesse caso particular, colocou-as sob o mesmo regime jurídico dos bens de uso comum do povo e de uso especial (art. 100 do CC).

Para José Afonso da Silva, “a regra não abrange nem as terras devolutas da União, nem as dos Municípios, embora a destes até devesse abranger. A indisponibilidade constitucionalmente estabelecida depende de verificação de sua necessidade para a proteção indicada e significa — verificado esse pressuposto

inclusive na via judicial — que a alienação e mesmo a simples legitimação de posse dessas terras são nulas”.[56](#)

■ 19.8.14. Localização das usinas nucleares: necessidade de lei federal

Para serem instaladas, as usinas que operam com reator nuclear deverão ter a sua **localização** definida em **lei federal**.

Essa regra complementa a fixada no art. 21, XXIII, “a”, que exige aprovação e autorização, pelo **Congresso Nacional** (art. 49, XIV), para o funcionamento das usinas nucleares e somente para fins pacíficos.

Assim, toda e qualquer lei estadual, distrital ou municipal, inclusive Constituição estadual, ou Lei Orgânica, que vedar ou autorizar a instalação de usina nuclear em determinada região será inconstitucional por invadir a competência da União.

■ 19.9. FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM E IDOSO

■ 19.9.1. Família: conceito de entidade familiar

A **família** é a **base da sociedade** e terá **especial proteção** do Estado [57](#) (art. 226).

O conceito de família foi ampliado pelo texto de 1988, visto que, para efeito de proteção pelo Estado, foi reconhecida como **entidade familiar** também a **união estável**[58](#) entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Embora fique clara a preferência do constituinte pelo *casamento entre homem e mulher* (uma vez que estabelece que a lei deverá facilitar a conversão da **união estável** em casamento), ressaltamos a importância desse novo preceito constitucional (união estável), ampliando o conceito de entidade familiar.

Aprimorando o sistema anterior, que só reconhecia a sociedade biparental

(filhos de pai e mãe, tanto que as mães solteiras eram extremamente marginalizadas), fundado em ultrapassado modelo patriarcal e hierarquizado (Código Civil de 1916), a Constituição de 1988 reconheceu a **família monoparental**.

Nesse sentido, nos termos do art. 226, § 4.º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

O Estado, então, deverá assegurar proteção especial para as mães solteiras, os pais solteiros, a comunidade de pai ou mãe separados ou divorciados e eventuais filhos, as famílias instituídas por inseminação artificial, produção independente etc.

Prioriza-se, portanto, a **família socioafetiva** à luz da **dignidade da pessoa humana**, com destaque para a **função social da família**, consagrando a igualdade absoluta entre os cônjuges (art. 226, § 5.º) [59](#) e os filhos (art. 227, § 6.º). [60](#)

■ 19.9.2. União homoafetiva (união estável entre pessoas do mesmo sexo)

Carlos Roberto Gonçalves observa que vários são os requisitos para a configuração da **união estável**, sejam eles de *ordem subjetiva* (“a) convivência *more uxorio*; b) *affectio maritalis*: ânimo ou objetivo de constituir família”) e de *ordem objetiva* (“a) **diversidade de sexos** — requisito que não mais se sustenta; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica”). [61](#)

Sobre o requisito da “**diversidade de sexos**”, contudo, conforme anota o autor, “por se tratar de modo de constituição de família que se assemelha a casamento, apenas com a diferença de não existir a formalidade da celebração, entendia-se, **até recentemente**, que a união estável só poderia decorrer de relacionamento entre pessoas de sexo diferente. A doutrina **considerava** da essência do casamento a heterossexualidade e classificava na categoria de ato

inexistente a união entre pessoas do mesmo sexo. (...). A matéria **ficava** assim excluída do âmbito do direito de família, gerando apenas efeitos de caráter obrigacional”.

E completa: “aos poucos, no entanto, eminentes doutrinadores começaram a colocar em evidência, **com absoluta correção**, a necessidade de atribuir verdadeiro **estatuto de cidadania às uniões estáveis homoafetivas**. Na jurisprudência, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul passou a reconhecer a união entre homossexuais como possível de ser abarcada dentro do conceito de entidade familiar, sob a forma de união estável homoafetiva, ao fundamento de que ‘a ausência de lei específica sobre o tema não implica ausência de direito, pois existem mecanismos para suprir as lacunas legais, aplicando-se aos casos concretos a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, em consonância com os preceitos constitucionais (art. 4.º da LINDB)’”.

Entendemos que deve ser feita uma interpretação mais ampla do art. 226, § 3.º (que discorre sobre a união estável entre homem e mulher), à luz do *caput*, que prestigia a **proteção da família**, e, especialmente, do princípio da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III, da CF/88).

Não temos dúvida de que o direito tem de evoluir para disciplinar a realidade social das uniões homoafetivas, assegurando o direito de herança, previdência, propriedade, sucessão e, sem dúvida, de acordo com a evolução da sociedade e o controle estatal, inclusive e naturalmente com a participação do Ministério Público, de adoção de crianças (cf. *item 19.9.12.4*) e qualquer outro direito assegurado à união estável como entidade familiar.

Parece, então, que a **união homoafetiva**, à luz do princípio da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III — regra-matriz dos direitos fundamentais), do **direito à intimidade** (art. 5.º, X), da **não discriminação**, enquanto objetivo fundamental do Estado (art. 3.º, IV), da **igualdade** em relação ao tratamento dado à união estável entre um homem e uma mulher (art. 5.º, *caput*), deva ser considerada **entidade familiar** e, assim, ter o tratamento e **proteção especial** por parte do Estado, exatamente como vem sendo conferido à união estável entre um homem e uma mulher.

Conforme argumenta Maria Berenice Dias, mostra-se “... impositivo reconhecer a existência de um gênero de união estável que comporta mais de uma espécie: união estável heteroafetiva e união estável homoafetiva. **Ambas merecem ser reconhecidas como entidade familiar.** Havendo convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas, estabelecida com o objetivo de constituição de família, mister reconhecer a existência de uma união estável. Independente do sexo dos parceiros, fazem jus à mesma proteção...”.⁶²

O STF, em decisão histórica, no julgamento da **ADI 4.277** e da **ADPF 132**, em 05.05.2011, reconheceu como constitucional a união estável entre pessoas do mesmo sexo, tendo sido dada **interpretação conforme à Constituição** para excluir qualquer significado do art. 1.723 do CC⁶³ que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Confira:

“Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem/mulher (gênero), seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A **proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal.** Homenagem ao **pluralismo** como valor sociopolítico-cultural. **Liberdade para dispor da própria sexualidade,** inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da **autonomia de vontade. Direito à intimidade e à vida privada.** Cláusula pétrea. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. **Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3.º da CF,** por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de ‘promover o bem de todos’. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana ‘norma geral negativa’, segundo a qual ‘o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido’. Reconhecimento do **direito à preferência sexual** como direta **emanação do princípio da ‘dignidade da pessoa humana’:** direito a **autoestima** no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. **Direito à busca da felicidade.** Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do **direito à liberdade sexual.** O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico

uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. (...). Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do **art. 1.723 do CC**, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a **utilização da técnica de ‘interpretação conforme à Constituição’**. Isso para **excluir** do dispositivo em causa qualquer **significado** que **impeça** o **reconhecimento** da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como **família**. Reconhecimento que é de ser feito segundo as **mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva**” (**ADI 4.277** e **ADPF 132**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011, Plenário, *DJE* de 14.10.2011).

Como desdobramento desse julgamento, considerando o entendimento firmado pelo STJ no **REsp 1.183.378/RS** (j. 25.10.2011), que decidiu inexistirem óbices legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo, o **CNJ** editou a **Res. n. 175/2013**, que veda às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo, sob pena de imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. [64](#)

■ 19.9.3. Transexualidade

A **Res. n. 1.955/2010** do Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras e procedimentos para a **cirurgia de transgenitalismo**, revogando a anterior, que disciplinava o assunto, Res. CFM n. 1.652/2002.

Nos termos de seus *considerandos*, destacamos que o paciente transexual é “... portador de **desvio psicológico permanente de identidade sexual**, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou autoextermínio”.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o **transexualismo** é reconhecido como uma patologia (*CID-10 F64.0*), [65](#) podendo ser conceituado como a vontade de viver e ser aceito como membro do sexo oposto, acompanhado, geralmente, do desejo de fazer com que o corpo seja o mais próximo daquele que se sonha, seja por cirurgia, seja por tratamento hormonal.

Fixa-se, ainda, o prazo de dois anos de continuidade do desejo de mudança de sexo e que não haja sintoma de qualquer outro transtorno mental. Isso quer dizer que a pessoa nasce com características físicas de um sexo, mas pensa e se comporta como uma pessoa do sexo oposto, não se confundindo o transexualismo com a homossexualidade. A alma, a essência, é de um sexo, mas o corpo físico e indesejado é do outro sexo.

A definição de **transexualismo** obedecerá (cf. o *art. 3.º da Res. CFM n. 1.955/2010*), no mínimo, aos seguintes critérios:

- desconforto com o sexo anatômico natural;
- desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto;
- permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no mínimo, dois anos;
- **ausência de transtornos mentais.**

Pode ser tanto a transformação do fenótipo masculino em feminino (**neocolpovulvoplastias**), com bons resultados cirúrgicos, do ponto de vista estético ou funcional, como do fenótipo feminino em masculino (**neofaloplastias**), uma vez que, neste último caso, ainda há dificuldades técnicas para a obtenção de bom resultado, seja no aspecto estético, seja no funcional.

Assim, por todo o exposto, várias decisões de tribunais estaduais e também do STJ (**SE 2.149**, Min. Barros Monteiro, *DJ* de 11.12.2006) vêm reconhecendo, com base nos princípios da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III); **proibição de discriminação por motivo de sexo** (art. 3.º, IV); **intimidade, vida privada e honra** (art. 5.º, X); **direito à saúde** (arts. 196 e s., especialmente o art. 199, § 4.º) etc.; o apoio do Estado para a mudança de sexo, inclusive pelo SUS, e, ainda, a autorização para mudança de nome e sexo no registro civil (adequando-se, assim, o documento formal à aparência do registrando e evitando, por consequência, constrangimento).

No STF, em decisão monocrática, a Ministra Ellen Gracie concedeu pedido

de Suspensão de Tutela Antecipada (**STA 185**), requerida pela União, contra ato da 3.^a Turma do TRF-4 que confirmou decisão de juízo de primeira instância, determinando que o SUS realizasse todas as cirurgias de transgenitalização (12.12.2007).

Em seu voto, esclarece: “não desconheço o sofrimento e a dura realidade dos pacientes portadores de transexualismo (patologia devidamente reconhecida pela Organização Mundial de Saúde: CID-10 F64.0), que se submetem a programas de transtorno de identidade de gênero em hospitais públicos, a entrevistas individuais e com familiares, a reuniões de grupo e a acompanhamento por equipe multidisciplinar, nos termos da Resolução 1.652/2002 do Conselho Federal de Medicina (revogada pela Resolução CFM n. 1.955/2010), com o objetivo de realizar a cirurgia de transgenitalização, pessoas que merecem todo o respeito por parte da sociedade brasileira e do Poder Judiciário”.[66](#)

Entretanto, tendo em vista que a decisão dada na ação civil pública repercutiria sobre a programação orçamentária federal e, assim, geraria impacto nas finanças públicas, a Ministra Ellen determinou a suspensão da medida judicial.

A decisão não afasta a realidade dos transexuais; ao contrário: reconhece-a. Deixou, porém, por questões orçamentárias, de reconhecer a obrigatoriedade de realização da cirurgia pelo SUS, e, por questões processuais, de analisar o mérito da ação.

Em momento seguinte, a Portaria n. 1.707/2008, do Ministério da Saúde, **instituiu**, no âmbito do Sistema Único de Saúde (**SUS**), o **processo transexualizador**, com previsão de ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Consequentemente, a **suspensão de tutela antecipada** (STA 185) em análise, bem como o agravo regimental interposto, foram julgados **prejudicados** pela perda superveniente do objeto (art. 21, IX, RISTF). Atualmente, o processo está disciplinado na Portaria n. 2.803/GM/MS/2013.

Assim, na prática, pelos argumentos expostos, sustentamos que o SUS tem o dever de arcar com os custos de referida cirurgia. Dessa forma, não temos

dúvida em afirmar que o Estado deverá reconhecer como **entidade familiar** aquela em que se tenha um transexual como membro, assegurando todos os direitos já defendidos para a união estável homoafetiva.

Nesse caso do transexual, uma vez realizada a cirurgia, se uma pessoa que era do fenótipo masculino se transformou em mulher, reconhecida a mudança de sexo inclusive no registro civil, parece-nos que poderá casar-se com um homem, e aqui teríamos um perfeito casamento.

O tema é muito novo e precisa de uma reflexão mais aprofundada pelo STF. Vamos aguardar...

■ 19.9.4. A união estável pode ser reconhecida em relação a uma menor de 14 anos estuprada que veio a se casar com o agressor, para efeitos de extinção de punibilidade quando era admitida (antes da revogação do art. 107, VII, do CP)?

Conforme noticiado pelo STF, de acordo com os autos do **RE 418.376**, “... o réu estuprou uma sobrinha aos nove anos de idade e com ela manteve relações sexuais até os doze anos, quando a engravidou. A partir daí, os dois passaram a viver maritalmente e a defesa de J. A. F. M. alega que ficou configurada a chamada união estável” (*Notícias STF*, 09.02.2006 — 19h05).

Configurada a união estável, tendo em vista que o fato ocorreu quando ainda vigorava o art. 107, VII, do CP (que **prescrevia** a extinção da punibilidade pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial), [67](#) propunha-se a sentença absolutória.

O STF, no entanto, por 6 votos a 3, entendeu não se aplicar a extinção da punibilidade em razão da gravidade do crime, com **violência presumida**, dadas as circunstâncias de a vítima ser menor de 14 anos e o Estado ter o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares (art. 226, § 8.º) e, ainda, o dever de proteger as crianças, os adolescentes e os jovens (art. 227, *caput*). Por isso, a relação não poderia caracterizar-se como união estável:

“EMENTA: Estupro. Posterior convivência entre autor e vítima. Extinção da punibilidade com base no art. 107, VII, do Código Penal. Inocorrência, no caso concreto. Absoluta incapacidade de autodeterminação da vítima. Recurso desprovido. O crime foi praticado contra criança de nove anos de idade, absolutamente incapaz de se autodeterminar e de expressar vontade livre e autônoma. Portanto, inviável a extinção da punibilidade em razão do posterior convívio da vítima — a menor impúbere violentada — com o autor do estupro. Convívio que não pode ser caracterizado como união estável, nem mesmo para os fins do art. 226, § 3.º, da Constituição Republicana, que não protege a relação marital de uma criança com seu opressor, sendo clara a inexistência de um consentimento válido, neste caso. Solução que vai ao encontro da inovação legislativa promovida pela Lei n. 11.106/2005 — embora esta seja inaplicável ao caso por ser lei posterior aos fatos —, mas que dela prescinde, pois não considera validamente existente a relação marital exigida pelo art. 107, VII, do Código Penal” (RE 418.376, Rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 09.02.2006, DJ de 23.03.2007).

■ 19.9.5. Família: assistência e proteção contra a violência doméstica. As particularidades da denominada Lei Maria da Penha (ADC 19 e ADI 4.424)

O Estado assegurará a **assistência** à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para **coibir a violência** no âmbito de suas relações (art. 226, § 8.º).

Percebam que essa proteção, dever do Estado, refere-se ao conceito amplo de entidade familiar, abrangendo, também, toda forma de união estável, e não somente a mulher, mas também o homem, filhos e qualquer de seus integrantes.

Avançando, de modo específico, a **Lei n. 11.340/2006** (*Lei Maria da Penha*), além de dar outras providências, criou mecanismos para **coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher**, em consonância com o § 8.º do art. 226 da Constituição Federal, com a *Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres* e com a *Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher*, dispondo sobre a criação dos **Juizados de Violência Doméstica e Familiar**

contra a Mulher, bem como alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.

O STF, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em **09.02.2012**, julgou procedente a **ADC 19** para declarar a constitucionalidade dos arts. 1.º, [68](#) [33](#) [69](#) e 41 [70](#) da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), tendo por fundamento o **princípio da igualdade**, bem como o **combate ao desprezo às famílias**, sendo considerada a **mulher** a sua **célula básica**.

O Tribunal, ainda, na mesma assentada, por maioria e também nos termos do voto do Relator, julgou procedente a **ADI 4.424** para, dando interpretação conforme aos arts. 12, I, [71](#) e 16, [72](#) ambos da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), declarar a **natureza incondicionada da ação penal** em caso de **crime de lesão, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico**. [72](#)

O então Presidente do STF, Min. Cezar Peluso, ficou **vencido** ao sustentar que a autonomia da mulher, mesmo que vítima de violência, deveria prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana.

Em suma, de acordo com o STF, os crimes de lesão corporal, ainda que leve ou culposa, praticados **contra a mulher no âmbito doméstico e familiar**, são de **ação penal pública incondicionada** (entendimento esse reafirmado pela Corte no julgamento do ARE 773.765 RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04.04.2014, *DJE* de 28.04.2014).

■ **19.9.5.1. Lei Maria da Penha: instrumento de proteção efetiva dos direitos fundamentais**

Determinou-se que, “ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o legislador teria utilizado meio adequado e necessário para fomentar o fim traçado pelo referido preceito constitucional. Aduziu-se **não ser desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação, visto que a mulher seria**

eminentemente vulnerável no tocante a constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado” (Inf. 654/STF).

A *Lei Maria da Penha* segue tendência do *novo direito civil constitucional* de se estabelecer o regramento não em código único, mas em destacados **microssistemas**, como o *ECA*, o *Estatuto do Idoso* etc., na linha do preconizado pelo **princípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais**.

■ **19.9.5.2. Não aplicação da Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)**

O STF declarou constitucional o art. 41 da Lei n. 11.340/2006, confirmando a regra segundo a qual aos crimes praticados com **violência doméstica e familiar contra a mulher**, independentemente da pena prevista, **não se aplica a Lei n. 9.099/99**, adequando-se esse entendimento aos **princípios da igualdade** e da **proporcionalidade**.

■ **19.9.5.3. Constitucionalidade das regras até que sejam estruturados os “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”**

Avançando, a Corte entendeu constitucional a previsão de criação dos *Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher* e, dessa forma, enquanto não estruturados, a previsão de serem acumuladas nas varas criminais as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Isso porque a lei facultou a sua criação (arts. 14, *caput*, e 29). No mais, trata-se de matéria de direito processual civil de competência da União, nos termos do art. 22, I, da CF/88.

Em conclusão sobre esse ponto, “por meio do referido art. 33, a *Lei Maria da Penha* não criaria varas judiciais, não definiria limites de comarcas e não estabeleceria o número de magistrados a serem alocados nos *Juizados de*

Violência Doméstica e Familiar. Apenas **facultaria** a criação desses juizados e **atribuiria** ao juízo da vara criminal a **competência cumulativa de ações cíveis e criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher**, haja vista a necessidade de conferir **tratamento uniforme, especializado e célere**, em todo o território nacional, às causas sobre a matéria” (*Inf. 654/STF*).

■ **19.9.5.4. Crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher: ação penal pública incondicionada**

Evocando os princípios da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III), da **igualdade substancial** (art. 5.º, I), do **dever da lei de punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais** (art. 5.º, XLI), bem como a regra do art. 226, § 8.º, da CF/88, segundo a qual o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando **mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações**, o STF, dando interpretação conforme a Constituição, estabeleceu que a ação penal para a apuração dos delitos domésticos de lesão corporal leve e culposa contra a mulher **independem de representação da vítima**. Trata-se de **ação penal pública incondicionada**.⁷³

A proteção constitucional perderia o seu sentido se, “verificada a agressão com lesão corporal leve, pudesse ela, depois de acionada a autoridade policial, recuar e retratar-se em audiência especificamente designada com essa finalidade, fazendo-o antes de recebida a denúncia. Dessumiu-se que deixar a mulher — autora da representação — decidir sobre o início da persecução penal significaria desconsiderar a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, bem como outros fatores, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implicaria relevar os graves impactos emocionais impostos à vítima, impedindo-a de romper com o estado de submissão” (*Inf. 654/STF*).

Em face do exposto, o ditado popular tem de ser revisto: **em briga de marido e mulher, o Estado, tomando conhecimento da lesão corporal (leve**

ou culposa) mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, deve meter a colher!

Finalmente, a *Lei Maria da Penha* determinou, em seu art. 41, a não aplicação das regras da Lei n. 9.099/95. Portanto, a **necessidade de representação** para crimes fixados em **outros diplomas legais**, como o Código Penal, ainda **persiste**. Dessa forma, exemplificando, nas hipóteses do CP, ainda se mostra indispensável a representação da vítima, como no crime de ameaça e nos cometidos contra a dignidade sexual.

■ 19.9.6. Casamento: regras gerais; gratuidade da celebração; efeito civil; liberdade de crença (centro espírita, candomblé, umbanda etc.)

O **casamento** é **civil** e é **gratuita** a **celebração** (art. 226, § 1.º).

Deve-se deixar claro que a gratuidade é da **celebração**, não alcançando, assim, o procedimento de habilitação para o casamento (arts. 1.525 a 1.532 do Código Civil e arts. 67 a 69 da *Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73)*, salvo quando se estiver diante de *reconhecidamente pobres*.

O art. 1.512, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão **isentos de selos, emolumentos e custas**, para as pessoas cuja **pobreza** for **declarada**, sob as penas da lei.

O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei (art. 226, § 2.º).

Nesse contexto, destacamos importante discussão decorrente do direito fundamental da liberdade de crença, culto e organização religiosa (art. 5.º, VI a VIII).

Conforme já estudamos, desde o advento da República vigora em nosso país a separação entre Estado e Igreja, inexistindo religião oficial da República Federativa do Brasil.

Portanto, se não há religião oficial e se a liberdade de crença religiosa está assegurada, indagamos se o casamento em **centro espírita** ou mesmo em **templo, catedral, sinagoga, terreiro, casa religiosa**, enfim, o casamento

celebrado por **líder de qualquer religião** ou **crença** teria o mesmo efeito civil do casamento realizado na religião católica, aplicando-se, por consequência, o art. 226, § 2.º.

O STF ainda não apreciou o tema, mas existem importantes julgados proferidos por Tribunais de Justiça.

Em primeiro lugar, destacamos julgamento proferido pelo **TJ/BA** que garante o mesmo efeito estabelecido para o casamento religioso (da religião católica) ao casamento realizado em centro espírita, prestigiando a **dignidade da pessoa humana** e a **liberdade religiosa**:

“EMENTA: (...). O casamento realizado num Centro Espírita, perante a autoridade reconhecida pela comunidade, tem validade jurídica e se equipara ao casamento celebrado perante autoridade pública, devendo ser registrado no registro próprio, observados os requisitos legais para o casamento” (MS n. 34.739-8/2005 — 10.03.2006).⁷⁴

Em igual sentido, a decisão proferida pelo **TJ/RS**:

“Nesse particular, entendo, primeiro, que o casamento no candomblé ou na umbanda tem o mesmo valor dos casamentos realizados nas religiões católicas e israelitas. Não devemos valorar mais os pactos realizados em grandes sinagogas ou catedrais pomposas, pelo fato de o casamento ter sido realizado em terreiros. Em todas essas cerimônias, o que está em questão, antes de mais nada é a fé que cada um dos parceiros tem numa força sobrenatural. Além disso, vale também, a confiança nos padres, pais de santo, rabinos e pastores, legítimos representantes das entidades dignas de fé de cada um. Enfim, mais do que um frio e burocrático casamento civil, a relevância do casamento religioso centra-se em valores transcendentais que o direito deve aprender a reconhecer seus efeitos” (TJ/RS, AC 70003296555, 8.ª C. Cív., Rel. Des. Rui Portanova, j. 27.06.2002).

■ 19.9.7. Divórcio: forma de dissolução do casamento civil à luz da EC n. 66/2010

O casamento civil, na **redação original** do art. 226, § 6.º, da CF/88, podia

ser dissolvido pelo divórcio, após: **a)** prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei; ou **b)** comprovada separação de fato por mais de 2 anos.

Durante muito tempo, apenas o casamento com vínculo indissolúvel tinha a proteção por parte do Estado. Essa situação foi modificada pela EC n. 9/77 (*estabelecia-se como requisito a prévia separação judicial por mais de 3 anos*) e depois regulamentada pela Lei n. 6.515/77 (*Lei do Divórcio*), estando a **dissolução do casamento** estabelecida no art. 226, § 6.º, da CF/88, como **direito fundamental da pessoa humana**.

Perceba-se que a literalidade da Constituição prevê o divórcio apenas para o **casamento civil**, e não para a união estável, a qual, reconhecida, por ser união de fato, sustentam os autores, pode ser “dissolvida” por situação fática ou acordo entre os conviventes.

O Novo CPC, contudo, avançando, prescreveu amplo tratamento para o reconhecimento ou a dissolução da união estável, nivelando ao casamento. Cf. arts. 53, I; 73, § 3.º; 189, II; 319, II; 600, parágrafo único; 620, II; **693**; 732; 733 e 1.048, § 3.º.

Outro ponto que se analisava era se a lei poderia estabelecer algum outro requisito para a conversão da separação em divórcio além do lapso temporal (alertando que a exigência de cumprimento de prazo era na **regra antiga**!).

É de mencionar o caso particular do art. 36, II, da Lei n. 6.515/77 (*Lei do Divórcio*), que permite contestação em ação de conversão de separação em divórcio ou divórcio direto alegando o *descumprimento das obrigações assumidas pelo requerente na separação*.

O STF enfrentou o tema e entendeu que referido dispositivo não foi recepcionado pela CF/88. Assim, foi **revogado**, uma vez que a Constituição só exigia, como exclusivo requisito para conversão da separação em divórcio, o **lapso temporal** (cf. **RE 387.271**, *Notícias STF*, 08.08.2007 e *Inf. 475/STF*).

Toda essa discussão sobre o lapso temporal como requisito para o divórcio deixa de ter sentido diante da promulgação da **EC n. 66/2010**, fruto da denominada “PEC do Amor”, como fora apelidada, no Senado Federal, a **PEC**

n. 28/2009.

Agora, pela **nova regra** contida no art. 226, § 6.º, o **casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio**; não há previsão de cumprimento de lapso temporal como requisito.

O divórcio, portanto, tendo em vista que a emenda entrou em vigor na data de sua publicação, poderá ser **imediatamente** implementado. Assim, em nosso entender, a EC n. 66/2010 **revogou** toda legislação infraconstitucional que ainda fazia menção à **ação de separação judicial**. Dessa forma, nesse ponto, o Código Civil está revogado (cf. arts. 1.572 e segs. do CC). [75](#)

E o que fez o CPC/2015? Ao tratar, em um muito bem-vindo capítulo próprio sobre as *ações de família*, o CPC/2015, inusitadamente, em seu art. 693, resgatou a já revogada ação de separação. Trata-se de disposição polêmica e que foi introduzida na última etapa do processo legislativo.

Em nosso entender, a nova regra está eivada de **vício congênito de inconstitucionalidade**. Estamos diante de ato nulo e que não encontra fundamento de validade na atual constituição que, a partir da EC n. 66/2010, não mais prevê a ação de separação.

Nessa linha, como bem esclareceu Flávio Tartuce, “...não vige mais o sistema bifásico de extinção da sociedade conjugal e do casamento. As ações em curso de separação judicial, sejam consensuais ou litigiosas, em regra, devem ser extintas sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica superveniente do pedido, salvo se já houver sentença prolatada. **Esse entendimento deve ser reafirmado, mesmo diante da emergência do Novo Código de Processo Civil**. No máximo, aplicando-se os princípios processuais da economia e da fungibilidade, pode o juiz da causa dar oportunidade para que as partes envolvidas adaptem o seu pedido, da separação judicial para o divórcio”. [76](#)

Lembramos, finalmente, a **Lei n. 11.441/2007**, que altera o CPC/73, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela via administrativa (“simplificação de procedimentos”, perspectiva essa mantida no CPC/2015 — arts. 610, 611 e 733, com as nossas críticas em relação à separação).

■ 19.9.8. Liberdade para o planejamento familiar: dignidade da pessoa humana e paternidade responsável

Nos termos do art. 226, § 7.º, fundado nos princípios da **dignidade da pessoa humana** e da **paternidade responsável**, o **planejamento familiar** é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, **vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas**.

A teor do art. 2.º da Lei n. 9.263/96 (*que regula o § 7.º do art. 226 da CF/88*), entende-se por planejamento familiar “... o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”.

Nesse sentido, citamos duas ações do Estado:

■ **distribuição de preservativos:** não só no *carnaval*, mas durante todo o ano, o que materializa o comando do art. 226, § 7.º;

■ **distribuição da “pílula do dia seguinte”:** ação nova que gerou muita polêmica no carnaval de 2008. “A pílula anticoncepcional de emergência (*levonorgestrel 0,75 mg*), também conhecida como *pílula do dia seguinte*, é um recurso anticoncepcional importante para evitar uma gravidez indesejada, após uma relação sexual desprotegida. (...) Não é abortiva, pois não interrompe uma gravidez estabelecida e seu uso deve se dar antes da gravidez. Os vários estudos disponíveis atestam que ela atua impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo, seja inibindo a ovulação, seja espessando o muco cervical ou alterando a capacitação dos espermatozoides. Portanto, o seu mecanismo de ação é basicamente o mesmo dos outros métodos anticoncepcionais hormonais (pílulas e injetáveis). (...) É um direito assegurado pela Constituição Federal e pela Lei n. 9.263/96, que regulamenta o planejamento familiar, o acesso das pessoas às informações, métodos e técnicas para a concepção e para a anticoncepção, cientificamente aceita e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas” (*Nota Técnica do Ministério da Saúde*).

■ 19.9.9. Criança, adolescente e jovem (EC n. 65/2010)

A Constituição de 1988 avança na proteção à criança, ao adolescente e ao jovem (EC n. 65/2010), fixando diversos direitos fundamentais.

Cabe alertar que o *Capítulo VII* do Título VIII da CF/88, em sua redação original, tratava da proteção da *família*, da *criança*, do *adolescente* e do *idoso*.

Observava-se um “salto” da adolescência para a condição de idoso, havendo, assim, preocupante lacuna de proteção estatal (ao menos em termos de previsão constitucional e até de políticas públicas) em relação a representativa parte da população, que são os **jovens**.

Segundo o *Parecer* da Comissão especial destinada a analisar a *PEC n. 138/2003*, que “dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude” e que veio a ser transformada, com modificações, na **EC n. 65/2010**, os **jovens** representam (dados de 2009) quase **50 milhões de brasileiros**, com idade entre 15 e 29 anos, sendo que, nesse universo, cerca de 34 milhões estão entre os 15 e 24 anos.

A Constituição fazia alguma previsão em relação aos jovens, só que muito tímida:

■ **art. 24, XV**: “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à **juventude**”;

■ **art. 7.º, XXXIII**: “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de **18** e de qualquer trabalho a menores de **16** anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”;

■ **art. 14, § 1.º, II, “c”**: “o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18 anos”;

■ **art. 60, § 4.º, do ADCT**: “para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de **jovens** e

adultos 1/3 (um terço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano”.

Havia, também, a existência de uma **Secretaria Nacional de Juventude**, vinculada à *Secretaria-Geral da Presidência da República*, e o **Conselho Nacional de Juventude**, nos termos da Lei n. 11.129/2005, implementado pela Lei n. 11.692/2008, que passou a reger o *Programa Nacional de Inclusão de Jovens — Projovem*.

Apesar dessas medidas, a previsão constitucional, repetimos, era muito **tímida** em relação à proteção **específica** dos **jovens**.

Foi nesse contexto que se promulgou a **EC n. 65/2010**, buscando, então, incentivar as atuações governamentais de apoio ao jovem, nessa fase tão difícil de sua vida, de transição entre a adolescência e a vida adulta, marcada por muitas incertezas e dificuldades.

De acordo com o Relatório da CCJ no SF, *Parecer n. 297/2009*, nessa fase “...também se encontra a parte da população nacional atingida pelos piores índices de desemprego, evasão escolar e mortes por homicídio, sem falar dos problemas relativos à sexualidade, ao abuso de drogas e ao envolvimento com a criminalidade. Não amparados por serviços diferenciados e eficientes de apoio educacional, psicológico e médico, esses jovens vivenciam diariamente os **conflitos inerentes à transição da adolescência para a vida adulta**. Experimentam, nessa fase, via de regra, a saída da escola e da casa dos pais, a procura de trabalho, a prestação do serviço militar, o casamento e a constituição de uma nova família. Passam, portanto, de um estado de indefinição e dependência a outro de responsabilidade e autonomia, sem vislumbrar a presença do Estado em seu horizonte”.

A proteção às crianças e aos adolescentes já era reforçada pela *Convenção sobre os Direitos da Criança*⁷⁷ e pelo *Estatuto da Criança e do Adolescente* (Lei n. 8.069/90⁷⁸) e, agora, a proteção aos **jovens** está prevista na Constituição pela **EC n. 65/2010**, devendo, na dicção do art. 227, § 8.º, I, II, ser editado o **Estatuto da Juventude**, destinado a regular os direitos dos jovens, bem como pelo **Plano Nacional de Juventude**, de duração decenal, visando à

articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.

Nesse sentido, cumprindo o comando constitucional, a **Lei n. 12.852/2013** instituiu o *Estatuto da Juventude* e dispôs sobre os *direitos dos jovens*, os *princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude* e o *Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE)*.

Para efeitos conceituais, de acordo com o *Estatuto da Criança e do Adolescente* (art. 2.º) e com a *Lei n. 12.852/2013* (art. 1.º, § 1.º, na linha do que já estabelecia o art. 2.º da Lei n. 11.692/2008), considera-se:

- **criança**: a pessoa até *12 anos* de idade incompletos;
- **adolescente**: a pessoa entre *12 e 18 anos* de idade; [79](#)
- **jovem**: as pessoas com idade entre *15 e 29 anos* de idade.

É dever da **família**, da **sociedade** e do **Estado**, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, **assegurar** à criança, ao adolescente e ao jovem (**EC n. 65/2010**), com absoluta **prioridade**, o direito (art. 227, *caput*):

- à vida;
- à saúde;
- à alimentação;
- à educação;
- ao lazer;
- à profissionalização;
- à cultura;
- à dignidade;
- ao respeito;
- à liberdade;
- à convivência familiar e comunitária.

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:

- **recursos públicos:** aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
- **portadores de deficiência:** criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

■ 19.9.10. Criança, adolescente e jovem: proteção especial

O art. 227, § 3.º, assegura à criança, ao adolescente e ao jovem direito à **proteção especial**, que abrangerá:

- **proibição** de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos;
- idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, que deverá ser na condição de **aprendiz** até os 16 anos (art. 7.º, XXXIII);
- **garantia** de direitos previdenciários e trabalhistas;
- **garantia** de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola (**EC n. 65/2010**);
- **garantia** de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
- **obediência** aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

■ **estímulo** do Poder Público, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado (**família substituta** da família natural — arts. 28 e s. do ECA);

■ **programas** de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem (**EC n. 65/2010**) dependente de entorpecentes e drogas afins.

Como desdobramento dessa proteção especial por parte do Estado, o art. 227, § 4.º, estabelece que a lei **punirá** severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente, e em reforço da garantia de proteção às crianças e aos adolescentes e atendimento dos direitos, o constituinte determina a observância do art. 204 — garantia de recursos orçamentários.

■ 19.9.11. Alienação parental

A **Lei n. 12.318/2010** dispôs sobre a **alienação parental**, tema que deverá ser aprofundado no *direito civil*.

De acordo com o seu art. 2.º, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que **repudie** genitor ou que cause **prejuízo** ao estabelecimento ou à manutenção de **vínculos** com este.

A lei, de maneira interessante, enumera formas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:

- realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
- dificultar o exercício da autoridade parental;
- dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;

- dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
- omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
- apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou o adolescente;
- mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

Dessa forma, a prática de ato de alienação parental fere o **direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável**, prejudica as relações de **afeto** com o genitor e com o grupo familiar, constitui **abuso moral** contra a criança ou o adolescente e **descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda**.

■ 19.9.12. Adoção

■ 19.9.12.1. Regras gerais sobre adoção

Nos termos do art. 227, § 5.º, a **adoção** será **assistida pelo Poder Público**, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros, estando a matéria disciplinada especialmente na *Lei Nacional da Adoção (Lei n. 12.010/2009)*.

A adoção obedecerá a processo judicial, e os seus efeitos, por regra, só começam a partir do **trânsito em julgado** da sentença, **exceto** se o adotante vier a **falecer** no curso do procedimento, caso em que terá força retroativa à data do óbito.

Respeitando a **dignidade da pessoa humana**, o art. 227, § 6.º, da CF/88

dispõe que os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, inclusive sucessórios, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Esse tratamento não discriminatório deverá ser observado, também, se a adoção for realizada por entidade familiar constituída por **união estável**.

■ 19.9.12.2. *Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6.º. Posição do STF na AR 1.811*

A importante conquista estabelecida no **art. 227, § 6.º**, CF/88, que assegura a impossibilidade de qualquer tratamento discriminatório entre **filhos biológicos** (frutos ou não da relação de casamento) ou **adotivos** foi analisada pelo STF no julgamento da **AR 1.811** (j. 03.04.2014).

Em um primeiro momento, a 1.^a Turma do STF negou a uma filha adotiva o direito a herança relacionado à sucessão que se deu em 1980. Entenderam os Ministros que esta deveria ser regida pela lei vigente à época, que, no caso, fazia distinção em relação aos filhos adotivos (RE 231.223).

Proposta a ação rescisória, objetivava a filha adotiva a desconstituição da coisa julgada firmada no primeiro julgamento, requerendo, então, a aplicação da regra contida na Constituição de 1988 (art. 227, § 6.º) que teria confirmado o disposto no art. 51 da Lei n. 6.515/77 que não previa qualquer discriminação.

O STF, **contudo**, por maioria (6 x 3), entendeu que o art. 51 da Lei n. 6.515/77 (não discriminatório) teria como destinatários **apenas** os filhos **biológicos**, e **não** os **adotivos**, que, no caso, eram disciplinados pelo art. 377 do CC/1916 (discriminatório) e que veio a ser revogado **apenas** com a promulgação da CF/88. Assim ficou estabelecida a ementa:

“EMENTA: (...). A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6.º, da Carta de 1988. Precedente: RE n. 163.167/SC, 1.^a T., Relator Min. Ilmar Galvão, *DJ* de 08.09.95” (**AR 1.811**, Rel. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, j. 03.04.2014, Plenário, *DJE* de 29.10.2014).

Com o máximo respeito, entendemos que a divergência tinha razão, nos termos do voto do Min. Cezar Peluso, acompanhado por Ayres Britto e Cármen Lúcia. Os Ministros vencidos sustentavam que todas as normas, inclusive as do CC/1916, seriam inconstitucionais por afrontar o **princípio da isonomia**, que, naturalmente, era assegurado na Constituição anterior. A atual Constituição apenas teria explicitado uma regra que já deveria estar reconhecida.

Abominamos qualquer tipo de discriminação e entendemos que a Corte teria elementos para aferir esse vício de inconstitucionalidade de norma anterior à CF/88 perante a Constituição que vigia à época de sua aplicação, tanto que essa falta de compatibilização é um dos fatores para se reconhecer a não recepção do ato normativo e, portanto, a sua revogação (cf. *item 4.8.1*).

Quem sabe, no futuro, possa a Corte **reverter** esse posicionamento que acabou, na prática, gerando discriminação entre os filhos já que, inegavelmente, a convivência entre eles continuará durante a vigência do texto de 1988. Partindo da premissa (para nós, falsa) de que o art. 227, § 6.º, CF/88, não se aplica para situações que se consumaram antes de 1988, nas hipóteses de leis discriminatórias em relação a filhos biológicos ou adotivos, ficamos imaginando duas adoções, uma antes de 1988, sem eventual determinado direito, e outra, já na vigência da Constituição, com o reconhecimento desse direito! Inegavelmente, um complicado paradoxo.

■ 19.9.12.3. Adoção internacional

A **adoção internacional**, regulada pelo ECA (e não pelo CC, a teor dos arts. 51 e 52 do ECA) e, também, pela *Convenção Relativa à Proteção e Cooperação Internacional em Matéria de Adoção Internacional* (Dec. n. 3.087/99), caracteriza-se como o **único modo de colocação em família substituta estrangeira**. Interpretando o art. 31 do ECA, parece constituir medida excepcional, e, assim, caminha a doutrina e a jurisprudência no sentido de **preferir** a adoção por brasileiro ou estrangeiro residente no País àquela para fora do Brasil (internacional).⁸⁰ De qualquer forma, acima de tudo, no caso

concreto, deverá o juiz observar o interesse do adotando.

■ 19.9.12.4. Adoção por casal homoafetivo ou transexual

Conforme já verificamos, admitimos a proteção, por parte do Estado, da entidade familiar formada pela união homoafetiva ou por casal transexual.

Desde que haja minucioso estudo psicossocial por equipe multidisciplinar e reconhecimento pelo juiz, sempre buscando o melhor para o adotando, parece-nos possível a adoção por casal homoafetivo (ou transexual), consoante entendeu o TJ/RJ: “a afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho à adoção de menor, se não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de deformar o caráter do adotado...” (AC 14.332/98, 9.^a C. Cív., Rel. Des. Jorge de Miranda Magalhães, *DORJ* de 28.04.1999).

Em outro caso, dentre tantos já apreciados pelo Judiciário brasileiro, o MP do Paraná questionou o pedido de adoção feito por casal homoafetivo, já que a criança era menor de 12 anos e, assim, não poderia exprimir e opinar sobre a sua vontade. Ainda, discutiu o sexo do menor.

O **TJPR**, de maneira interessante, negou o pedido feito pelo MP. Vejamos a ementa do acórdão: “APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA TERMINATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DEFERIDA. **LIMITAÇÃO QUANTO AO SEXO E À IDADE DOS ADOTANDOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS ADOTANTES. INADMISSÍVEL.** AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como entidade familiar, com origem em um vínculo afetivo, a merecer tutela legal, não há razão para limitar a adoção, criando obstáculos onde a lei não prevê. 2. Delimitar o sexo e a idade da criança a ser adotada por casal homoafetivo é transformar a sublime relação de filiação, sem vínculos biológicos, em ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente

desprovido de amor e comprometimento”.

Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário para o STF. A Min. Cármen Lúcia negou seguimento ao recurso por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado pela Corte na ADI 4.277 e na ADPF 132 (**RE 846.102**, j. 05.03.2015, *DJE* de 18.03.2015). [81](#)

■ 19.9.13. Direito de ação de investigação de paternidade: a problemática da submissão coercitiva ao exame de DNA

Não resta dúvida de que a Constituição assegura como direito fundamental a ação de investigação de paternidade, uma vez que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado.

A questão que se coloca é se seria admitida a condução coercitiva para o exame de DNA.

Por regra, o STF entende que “discrepa, a mais não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas — preservação da **dignidade humana**, da **intimidade**, da **intangibilidade do corpo humano**, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer — provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, ‘debaixo de vara’, para coleta do material indispensável à feitura do exame **DNA**. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos” (HC 71.373, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.11.94, *DJ* de 22.11.96).

A inadmissibilidade da submissão coercitiva ao exame de DNA é a **regra**. Contudo, em outro julgado, o Pleno do STF determinou a realização (contra a vontade da suposta mãe) do exame de DNA na placenta da cantora mexicana *Gloria Trevi*, cujo filho teria sido, conforme acusado, fruto de estupro ocorrido nas dependências da Polícia Federal.

No caso concreto, os Ministros entenderam que o interesse público prevaleceu sobre o particular da suposta mãe: “Coleta de material biológico da

placenta, com propósito de se fazer exame de DNA, para averiguação de paternidade do nascituro, embora a oposição da extraditanda. (...) Bens jurídicos constitucionais como ‘moralidade administrativa’, ‘persecução penal pública’ e ‘segurança pública’ que se acrescem — como bens da comunidade, na expressão de Canotilho — ao direito fundamental à honra (CF, art. 5.º, X), bem assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de estupro da extraditanda, nas dependências da Polícia Federal, e direito à imagem da própria instituição, em confronto com o alegado direito da reclamante à intimidade e a preservar a identidade do pai de seu filho” (**Rcl 2.040-QO**, Rel. Min. Néri da Silveira, em j. 21.02.2002, *DJ* de 27.06.2003).

Esse segundo julgado está na linha do que defendeu Alexandre de Moraes ao criticar a regra geral adotada pelo STF no sentido da prevalência do direito da intimidade e intangibilidade do corpo humano.

Segundo o ilustre autor, enaltecendo os princípios da **relatividade dos direitos e garantias fundamentais, convivência das liberdades públicas, concordância das normas constitucionais**, há importante decisão trazida por *Francisco Llorente*, do Supremo Tribunal Constitucional espanhol, “... que entendeu que os direitos constitucionais à intimidade e à integridade física não podem converter-se em previsão que consagre a impunidade, com desconhecimento das obrigações e deveres resultantes de uma conduta que teve uma íntima relação com o respeito a possíveis vínculos familiares (*Derechos fundamentales y principios constitucionales*. Barcelona: Ariel, 1995, p. 152 e 178).” [82](#)

Finalmente, conforme já estudado no *item 6.7.1.17.4.2*, analisando o instituto da coisa julgada, em **situação excepcionalíssima**, o STF afastou a alegação de segurança jurídica (coisa julgada) para fazer valer o *direito fundamental de que toda pessoa tem de conhecer as suas origens (princípio da busca da identidade genética)*, especialmente se, à época da decisão que se procura rescindir, não se pôde fazer o exame de **DNA**.

A decisão foi tomada, em **02.06.2011**, por **7 x 2**, no julgamento do **RE 363.889**, concedendo à recorrente o direito de, depois de mais de 10 anos, voltar

a pleitear, perante o suposto pai, a realização do **exame de DNA**, tendo em vista que, na primeira decisão, embora beneficiária da assistência judiciária, a recorrente não podia arcar com as custas para a sua realização.

Cabe destacar o **voto vencido** do **Min. Marco Aurélio**, que, dentre outros aspectos, apontou a inexistência de efeito prático da decisão que acabava de ser tomada, na medida em que, como afirmou, “o demandado (suposto pai) não pode ser obrigado a fazer o exame de DNA”, realçando que a negativa de realização do exame não leva à **presunção absoluta** de que é verdadeiramente o pai.

■ 19.9.14. Portadores de deficiência

A proteção e amparo aos portadores de deficiência apareceu em sede constitucional somente com EC n. 12/78, projeto de autoria do Deputado Federal Thales Ramalho.

No texto de 1988, os arts. 227, § 2.º, e 244 estabelecem que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às **pessoas portadoras de deficiência**.

Embora a regra esteja inserida no capítulo sobre *família, criança, adolescente, jovem e idoso*, a proteção aos portadores de deficiência deve ser estudada como **direito fundamental da pessoa humana**.

Destacamos, conforme já tão apontado neste trabalho, o **Decreto Legislativo n. 186/2008**, que aprova o texto da *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* e de seu *Protocolo Facultativo*, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgados pelo **Decreto n. 6.949, de 25.08.2009**, tendo sido, assim, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de **norma constitucional**.

Em seu preâmbulo estabelece-se que a “**deficiência**” é um **conceito em evolução** e que resulta da **interação** entre *pessoas com deficiência* e as barreiras devidas às *atitudes* e ao *ambiente* que impedem a plena e efetiva

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

De acordo com o art. 2.º, para os propósitos da Convenção, “**“discriminação por motivo de deficiência”** significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável”.

Destacam-se, ainda, como **princípios** da Convenção:

- o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;
- a não discriminação;
- a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
- o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;
- a igualdade de oportunidades;
- a acessibilidade;
- a igualdade entre o homem e a mulher;
- o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.

Ainda, em termos normativos, lembramos as Leis ns. 7.853/89 e 10.098/2000, uma vez que, conforme visto, a Constituição estabelece expressa previsão de proteção para a criança, o adolescente e o jovem (art. 227, § 1.º, II, da CF/88).

A Lei n. 11.982/2009 incluiu um parágrafo único ao art. 4.º da Lei n. 10.098/2000, o qual estabelece, de maneira bastante interessante, que os

parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível.

Assegura-se, como direito fundamental, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência (art. 7.º, XXXI), visto que, em prestígio ao princípio da isonomia substancial ou material e como modalidade de ação afirmativa, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, VIII).

Por fim, o dever do Estado de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II) está materializado como atividade de assistência social (art. 203, IV e V) e atendimento educacional (art. 208, III).

■ 19.9.15. Inimputabilidade penal

Nos termos do art. 228 da CF/88, são penalmente inimputáveis os menores de **18 anos**, sujeitos às normas da legislação especial.

Muito se cogita a respeito da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Para tanto, o instrumento necessário seria uma **emenda à Constituição** e, portanto, manifestação do poder constituinte derivado reformador, limitado juridicamente.

Neste ponto, resta saber: eventual EC que reduzisse, por exemplo, de 18 para 16 anos, a maioridade penal violaria a cláusula pétrea do direito e garantia individual (art. 60, § 4.º, IV)?

Embora parte da doutrina assim entenda, [83](#) para nós é **possível** a redução de 18 para 16 anos, uma vez que apenas não se admite a proposta de emenda (PEC) tendente a abolir direito e garantia individual. Isso não significa, como já interpretou o STF, que a matéria não possa ser modificada.

Reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos, o direito à

inimputabilidade, visto como garantia fundamental, não deixará de existir.

A sociedade evoluiu, e, atualmente, uma pessoa com 16 anos de idade tem total consciência de seus atos, tanto é que exerce os direitos de cidadania, podendo propor a ação popular e votar. Portanto, em nosso entender, eventual PEC que reduza a maioria penal de 18 para 16 anos é totalmente constitucional. O limite de 16 anos já está sendo utilizado e é fundamentado no parâmetro do exercício do direito de votar e à luz da razoabilidade e maturidade do ser humano.

Observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “timbra o texto, no art. 228, em consagrar a inimputabilidade penal do menor de dezoito anos. É incoerente esta previsão se se recordar que o direito de votar — a maioria política — pode ser alcançado aos dezesseis anos...”.[84](#)

■ 19.9.16. Dever de reciprocidade entre pais e filhos

Segundo a proposta elaborada pela *Comissão Afonso Arinos*, o art. 229 traz importante **regra da vida**: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

■ 19.9.17. Idosos

■ 19.9.17.1. *Princípios da solidariedade e proteção à luz da “reserva do possível”*

À luz dos **princípios da solidariedade** e **proteção**, a **família**, a **sociedade** e o **Estado** têm o dever de **amparar as pessoas idosas**, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida [85](#) (art. 230).

O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, sendo obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Nesse contexto, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus **lares**.

A Lei n. 8.842/94 (*Política Nacional do Idoso*) e a Lei n. 10.741/2003 (*Estatuto do Idoso*) consideram **idoso** toda pessoa com idade igual ou superior a **60 anos**.

A velhice tem proteção como direito previdenciário (art. 201, I) e como direito assistencial (art. 203, I e V).

Porém, como anotam Mendes, Coelho e Branco, as políticas públicas de proteção ao idoso devem conciliar-se com os recursos orçamentários (art. 117 do *Estatuto do Idoso*). “Noutras palavras, em que pesem as generosas promessas desse *Estatuto*, aqui, como em tudo o que diz respeito à efetivação de direitos sociais, reina, impiedosa, a **reserva do possível**”.⁸⁶

■ 19.9.17.2. Idoso e transporte público: “*constitucionalismo fraternal*” ou “*altruístico*” — “*ações distributivistas e solidárias*” — “*direito fraternal*”

A regra do art. 230, § 2.º, garante aos **maiores de 65 anos** a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Em nosso entender, trata-se de **norma de eficácia plena**, que, portanto, independe de complementação infraconstitucional.

Tal previsão constitucional é disciplinada pelo art. 39 do *Estatuto do Idoso*, que assegura aos maiores de 65 anos de idade a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, dispositivo declarado constitucional pelo STF:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 39 da Lei n. 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), que assegura gratuidade dos transportes públicos urbanos e semiurbanos aos que têm mais de 65 (sessenta

e cinco) anos. Direito constitucional. Norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Norma legal que repete a norma constitucional garantidora do direito. Improcedência da ação. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2.º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (**ADI 3.768**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.09.2007, *DJ* de 26.10.2007).

Nesse caso concreto, o Min. Carlos Ayres Britto observou que a relatora havia retratado “o advento de um novo **constitucionalismo fraternal** ou, como dizem os italianos, ‘**altruístico**’, com **ações distributivistas e solidárias**”. Segundo ele, “não se trata de um direito social, mas de um **direito fraternal** para amainar direitos tradicionalmente negligenciados” (*Notícias STF*, 19.09.2007 — 20h50).

■ 19.9.17.3. *Celeridade do processo e crimes praticados contra os idosos*

Conforme já estudamos no *capítulo do Poder Judiciário*, o art. 94 do **Estatuto do Idoso** (Lei n. 10.741/2003) estabelece que aos crimes previstos na referida Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, **aplica-se o procedimento previsto na Lei n. 9.099/95** (Juizados) e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Esse dispositivo foi questionado na **ADI 3.096**, ajuizada pelo PGR, e entendeu o STF que a aplicação da Lei n. 9.099/95 é apenas em relação aos **aspectos processuais**, buscando, na ideia de efetividade do processo, que este termine mais rapidamente, até porque a vítima é idosa. Nesse sentido:

“EMENTA: (...). Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão ‘do Código Penal e’. Aplicação **apenas do procedimento sumaríssimo**

previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. **Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime.** 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003” (ADI 3.096, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.06.2010, Plenário, DJE de 03.09.2010).

■ 19.10. ÍNDIOS

■ 19.10.1. Os índios no constitucionalismo brasileiro

Analisando as Constituições brasileiras, percebe-se que foi somente na de **1934** que apareceu pela primeira vez a proteção aos índios, naquele texto denominados **silvícolas**.

Como já visto no *item 2.5.5*, a Constituição de 1934 inaugura a ideia de **Constituição social**, sofrendo forte influência da *Constituição de Weimar*, da Alemanha, de 1919, evidenciando-se, assim, os direitos de segunda dimensão sob a perspectiva do Estado Social de Direito (democracia social).

A proteção aos silvícolas foi mantida nos textos que seguiram (1937, 1946, 1967, EC n. 1/69), atingindo ampla previsão na CF/88, **87** que substituiu a expressão “silvícola” (“aquele que nasce ou vive na selvas; selvagem” — *Dicionário Aurélio*) por **índios**. **88**

■ 19.10.2. Proteção das “minorias nacionais” e a importância da “terra”

Em relação à proteção das minorias, conforme se observa no site da PGR, sobressai o importante papel da 6.^a *Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal*, órgão setorial de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional dos Procuradores da República, no tocante aos temas relativos aos *povos indígenas e outras minorias étnicas*, tendo especial

atenção:

- os **quilombolas**; [89](#)
- as **comunidades extrativistas**;
- as **comunidades ribeirinhas** e os **ciganos**.

“Todos esses grupos têm em comum um modo de vida tradicional distinto da sociedade nacional de grande formato. De modo que o grande desafio para a 6.^a CCR, e para os Procuradores que militam em sua área temática, é assegurar a pluralidade do Estado brasileiro na perspectiva **étnica** e **cultural**, tal como constitucionalmente determinada”. [90](#)

Nesse contexto, a **terra** adquire um particular significado como instrumento de consagração do direito fundamental da **moradia** (art. 6.º da CF/88) e, assim, da **dignidade da pessoa humana**, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1.º, III).

Segundo assentou o Min. Ayres Britto, no julgamento da ACO 312, a terra, para o índio, “... não é um bem mercantil, passível de transação. ‘Para os índios, **a terra é um totem horizontal, é um espírito protetor, é um ente com o qual ele mantém uma relação umbilical**’” (*Notícias STF*, 02.05.2012).

Bem anota Daniel Sarmiento que, nessas comunidades, a terra caracteriza-se como importante mecanismo para manter a união do grupo, permitindo, dessa forma, a sua continuidade ao longo do tempo, assim como a preservação da cultura, dos valores e de seu modo particular de vida dentro da comunidade.

Consequentemente, continua o ilustre professor, “privado da terra, o grupo tende a se dispersar e a desaparecer, tragado pela sociedade envolvente...”. E completa: “por isso, a perda da identidade coletiva para os integrantes destes grupos costuma gerar crises profundas, intenso sofrimento e uma sensação de desamparo e de desorientação, que dificilmente encontram paralelo entre os integrantes da cultura capitalista de massas. *Mutatis mutandis*, romper os laços de um índio ou de um quilombola com o seu grupo étnico é muito mais do que impor o exílio do seu país para um típico ocidental”. [91](#)

■ 19.10.3. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

■ 19.10.3.1. *Bens da União. Terras destinadas à posse permanente dos índios: bens públicos de uso especial*

As *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios*, apesar de consideradas **bens da União** (art. 20, XI), destinando-se à **posse permanente** dos silvícolas, são **inalienáveis** e **indisponíveis**, e os direitos sobre elas, **imprescritíveis**.

A vinculação à União está reforçada no art. 22, XIV, que estabelece ser competência privativa da União legislar sobre populações indígenas.

Por essas características e por possuírem destinação específica, embora não previstas expressamente no art. 99, II, do CC, as *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios* podem ser classificadas como **bens públicos de uso especial**.

Em relação a essa regra, qual seja, o conceito segundo o qual as **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União**, devemos lembrar uma exceção bastante peculiar.

De acordo com o **art. 64** da Constituição de **1891**, pertencem aos **Estados** as minas e **terras devolutas** situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.

“As terras dos **aldeamentos indígenas** que se **extingiram** antes da Constituição de 1891, por haverem *perdido o caráter de bens destinados a uso especial*, passaram à categoria de **terras devolutas**. Uma vez reconhecidos como terras devolutas, por força do art. 64 da Constituição de 1891, os **aldeamentos extintos** transferiram-se ao **domínio dos Estados**” (**ADI 255**, Rel. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.03.2011, Plenário, *DJE* de 24.05.2011. No mesmo sentido: **RE 212.251**, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 23.06.98, 1.^a Turma, *DJ* de 16.10.98).

Esse exemplo nos faz resgatar a **S. 650/STF** que reflete o entendimento no sentido de deixar de considerar “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”

e, portanto, bens da União (art. 20, I e XI, CF/88), as terras de aldeamentos **extintos**, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

Dentro desse contexto, o STF, no julgamento da **PET 3.388** (*Raposa Serra do Sol* — cf. *item 19.10.7.2*) — e que tem servido de **paradigma** para o julgamento de questões envolvendo a demarcação de terras indígenas, definiu a necessidade de se observar a **data da promulgação da CF/88 (05.10.88)** como sendo o **marco temporal** para se verificar se a terra estava ou não ocupada por índios.

Dessa forma, não se inclui no conceito de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” aquelas que eram ocupadas no passado e não o são mais, estando extintos os aldeamentos, nem aquelas que venham a ser ocupadas a partir da promulgação da Constituição. Em razão da importância, pedimos vênica para citar parte do referido voto:

“I — o marco temporal da ocupação. Aqui, é preciso ver que a nossa Lei Maior trabalhou com data certa: a data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) como insubstituível referencial para o reconhecimento, aos índios, ‘dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam’. **Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988.** Marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação de área indígena. Mesmo que essa referência estivesse grafada na Constituição anterior. É exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum outro. Com o que se evita, a um só tempo: a) a fraude da subitânea proliferação de aldeias, inclusive mediante o recrutamento de índios de outras regiões do Brasil, quando não de outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes da demarcação; b) a violência da expulsão de índios para descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas terras, à data da vigente Constituição. **Numa palavra, o entrar em vigor da nova Lei Fundamental Brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena nesse delicado tema da ocupação das terras**

a demarcar pela União para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígine” (voto do Min. Ayres Britto, fls. 67 e 68).

A única **exceção** que foi destacada em referido julgado refere-se às situações de “**esbulho renitente**”, constatado diante de “situação de disputa possessória, fática ou judicializada, ou de outra espécie de inconformismo que pudesse caracterizar a presença de não índios” como **ilegítima** e, assim, diante das disputas, permitir fosse reconhecido o caráter da tradicionalidade. [92](#)

■ 19.10.3.2. Conceito

Caracterizam-se como *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios*, consoante o art. 231, § 1.º, aquelas que, necessariamente, apresentam as seguintes indissociáveis características:

- são habitadas em caráter permanente;
- são utilizadas para as atividades produtivas dos índios;
- são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar;
- são necessárias à reprodução física e cultural dos índios, segundo seus usos, costumes e tradições.

■ 19.10.3.3. Nulidade e extinção dos atos que atentem contra as “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”

São **nulos** e **extintos**, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios* ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 6.º).

A única **exceção** trazida pela CF/88 a não caracterizar a nulidade e a extinção dos atos refere-se aos atos que se apresentem como de relevante interesse público da União, segundo o que dispuser **lei complementar**.

Por consequência, a nulidade e a extinção de referidos atos não gerarão nenhum direito a indenização ou a ações contra a União, em face do órgão de assistência do índio (*Fundação Nacional do Índio — FUNAI*,⁹³ vinculada ao Ministério da Justiça) ou perante os próprios silvícolas, salvo, na forma do que dispuser a lei, no tocante às **benfeitorias** derivadas da ocupação de **boa-fé**.

Naturalmente, nessa única hipótese indenizatória, a ação deverá ser proposta em face da **União**, e não dos índios ou da FUNAI, uma vez que é a União a responsável por “... velar e impedir a prática de atos atentatórios aos direitos dos índios sobre as terras por eles ocupadas, que são bens dela”.⁹⁴

Para citar um exemplo, temos a **ACO 312**, que foi ajuizada em 1983 e julgada quase 30 anos depois, em 02.05.2012, tendo como parâmetro o art. 198 da EC n. 1/69.

Tratava-se de ação civil originária, ajuizada pela FUNAI e pela União, objetivando a **declaração de nulidade** de títulos de propriedade sobre imóveis rurais localizados na área da Reserva Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, no sul da Bahia, que seria ocupada, desde tempos remotos, pelos índios *Pataxó Hã-hã-hãe*.

Entendeu o STF que “a demarcação prévia da área abrangida pelos títulos não seria, em si, indispensável ao ajuizamento da própria ação e que o STF poderia examinar se a área seria ou não indígena para decidir pela procedência ou não do pedido” (*Inf. 664/STF*).

Ainda, por maioria, o STF **declarou** a **nulidade** de todos os **títulos de propriedade rural** expedidos pelo Governo da Bahia cujas glebas se **localizavam dentro da área da Reserva Indígena**.

■ 19.10.4. Indigenato: fonte para o direito dos índios sobre as suas terras

A expressão “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” não tem nada que ver com o tempo de sua ocupação, não estando, portanto, relacionada a qualquer situação temporal, mas, sim, ao **modo tradicional** de ocupação das

terras pelos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

Consagra-se, então, a ideia do **indigenato**, ou seja, a tradição iniciada, segundo José Afonso da Silva, pelo Alvará de 1.º.04.1680, confirmado pela Lei de 06.06.1755, de sempre respeitar o direito dos índios sobre as terras.

Diz o mestre que “... o *indigenato* não se confunde com a ocupação, com a mera posse. O *indigenato* é a fonte primária e congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é um título adquirido...”. Assim, “... em face do direito constitucional indigenista, relativamente aos índios com habitação permanente, não há uma simples posse, mas um reconhecido direito originário e preliminarmente reservado a eles”. [95](#)

Dessa forma, “... a relação entre o indígena e suas terras não se rege pelas normas de direito civil. Sua posse extrapola a órbita puramente privada, porque não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu *habitat*, no sentido ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana”. [96](#)

■ 19.10.5. Usufruto exclusivo dos índios e a mineração em terras indígenas

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o **usufruto exclusivo** das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Não obstante essa regra geral, autoriza-se o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, dependendo, para tanto, de **expressa e formal autorização do Congresso Nacional**, ouvidas as comunidades afetadas e desde que se assegure aos índios, na forma da lei, a participação nos resultados da lavra (art. 231, § 3.º).

Referido processo de autorização se implementa, nos termos do art. 49, XVI, por meio de **decreto legislativo**, materializando competência exclusiva, portanto

indelegável, do Congresso Nacional.

A análise do Congresso Nacional deverá levar em consideração o **princípio da prevalência dos interesses indígenas**, tanto que o art. 176, § 1.º, estabelece que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas só poderão ocorrer desde que observados os critérios e condições específicas definidos em lei.

A restrição é tamanha que nem mesmo as *atividades garimpeiras*, em cooperativa ou não, serão admitidas dentro das terras indígenas, salvo, naturalmente, as atividades garimpeiras desenvolvidas pelos próprios silvícolas, uma vez que, conforme visto, eles têm o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 7.º, c/c o art. 174, §§ 3.º e 4.º).

■ 19.10.6. Regras constitucionais para a remoção dos grupos indígenas

É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, *ad referendum* do Congresso Nacional, em caso de **catástrofe** ou **epidemia que ponha em risco sua população**, ou no **interesse da soberania do País**, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco (art. 231, § 5.º).

Em qualquer dessas hipóteses, logo que cesse o risco, deve-se garantir o retorno imediato dos índios ao seu *habitat*.

Nesse contexto, há interessante decisão do STF no tocante à intimação de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha em CPI:

“EMENTA: (...) IV. Comissão Parlamentar de Inquérito: intimação de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha, fora do seu *habitat*: violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas (CF, arts. 215, 216 e 231). 1. A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é **vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela**

previstas (CF/88, artigo 231, § 5.º). 2. A tutela constitucional do grupo indígena, que visa a proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, a respectiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, quanto à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais. 3. Ademais, o depoimento do índio, que não incorporou ou compreende as práticas e modos de existência comuns ao ‘homem branco’ pode ocasionar o cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível de comprometimento do seu *status libertatis*. 4. Donde a necessidade de adoção de cautelas tendentes a assegurar que não haja agressão aos seus usos, costumes e tradições” (HC 80.240, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.06.01, *DJ* de 14.10.2005).

■ 19.10.7. Demarcação das terras indígenas

■ 19.10.7.1. Aspectos gerais

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, **competindo à União demarcá-las**, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231, *caput*).

As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio (*FUNAI*), serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido no Decreto n. 1.775/96, devendo referida demarcação administrativa ser aprovada por Portaria do Ministro da Justiça, que será homologada pelo Presidente da República e, posteriormente, registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da comarca da situação das terras.

Entendeu o STF ser **dispensada** a manifestação do Conselho de Defesa Nacional durante o processo homologatório, mesmo que a terra indígena se situe em região de fronteira (MS 25.483, Rel. Min. Carlos Britto, j. 04.06.07, *DJ* de 14.09.2007).

Por sua vez, o art. 67 do ADCT fixou o prazo de **5 anos** a partir da promulgação da Constituição para a União concluir a demarcação das terras indígenas.

Tal trabalho, contudo, ainda não está finalizado. Apesar disso, não se pode dizer que os índios não tenham os seus direitos assegurados, pois **independentemente de demarcação**.

Podemos afirmar, então, que o art. 67 do ADCT **não** previu prazo decadencial para a demarcação, tratando-se de **prazo programático**, e **não peremptório**. A regra deve ser entendida como instrumento para **estimular** a demarcação, até porque, conforme visto, nos termos do art. 231, § 4.º, as *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios* são **inalienáveis** e **indisponíveis**, e os *direitos* sobre elas, **imprescritíveis**.

O art. 25 da Lei n. 6.001/73 (*Estatuto do Índio*) dispõe que o reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas independerá de sua demarcação e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas.

Assim reconheceu o STF: “Terras indígenas — Demarcação. O prazo previsto no artigo 67 do ADCT não é peremptório. Sinalizou simplesmente visão prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e, portanto, a realização destes em tempo razoável” (MS 24.566, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.03.04, *DJ* de 28.05.2004). Ainda, e nesse mesmo sentido:

“EMENTA: I — Esta Corte possui entendimento no sentido de que o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT **não é decadencial**, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável. Precedentes. II — O processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é regulamentado por legislação própria — Lei 6.001/1973 e Decreto 1.775/1996 — cujas regras já foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RMS 22.212, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.05.2011, *DJE* de 18.05.2011).

Por derradeiro, destacou o STF que “a importância jurídica da demarcação

administrativa homologada pelo Presidente da República — ato estatal que se reveste de presunção *juris tantum* de legitimidade e de veracidade — reside na circunstância de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, embora pertencentes ao patrimônio da União (CF, art. 20, XI), acham-se afetadas, por efeito de destinação constitucional, a fins específicos voltados, unicamente, à proteção jurídica, social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais” (RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12.96, *DJ* de 14.02.97).

■ 19.10.7.2. *Raposa Serra do Sol*

O STF analisou a demarcação da Terra Indígena **Raposa Serra do Sol**, situada no Estado de Roraima.

O ponto principal era saber, além de eventuais vícios alegados no processo de demarcação, se a forma escolhida, qual seja, o modelo **contínuo**, apresentava-se adequada, em contraposição à demarcação por “ilhas” (ou tipo “queijo suíço”, como caracterizou o Min. Ayres Britto).

Trata-se da Portaria n. 534/2005, do Ministro da Justiça, homologada pelo Decreto presidencial de 15.04.2005. [97](#)

O Tribunal, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto do Relator, reajustado segundo as observações constantes do voto do Senhor Ministro Menezes Direito, declarando constitucional a **demarcação contínua** da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e determinando que sejam observadas as seguintes *condições* ou *condicionantes* (*salvaguadas*), consideradas pelo STF, apesar de críticas, como verdadeiros pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação (**Pet. 3.388**, Rel. Min. Carlos Britto, j. 19.03.2009, Plenário, *DJE* de 25.09.2009, republicado no *DJE* de 1.º.07.2010, **confirmado** no julgamento de sete **embargos de declaração** [98](#) opostos, j. 23.10.2013, *DJE* de 04.02.2014):

■ “o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas (art. 231, § 2.º, da Constituição Federal) pode ser

relativizado sempre que houver, como dispõe o art. 231, § 6.º, da Constituição, relevante interesse público da União, na forma de lei complementar;

■ o usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional;

■ o usufruto dos índios não abrange a pesquisa e lavra das riquezas minerais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando-se-lhes a participação nos resultados da lavra, na forma da lei;

■ o usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão de lavra garimpeira;

■ o usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política de defesa nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes (Ministério da Defesa e Conselho de Defesa Nacional), serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI;

■ a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atribuições, fica assegurada e se dará independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI;

■ o usufruto dos índios não impede a instalação, pela União Federal, de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além das construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e educação;

■ o usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;

■ o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela administração da área da unidade de conservação também afetada pela terra indígena com a participação das comunidades indígenas, que

deverão ser ouvidas, levando-se em conta os usos, as tradições e os costumes dos indígenas, podendo para tanto contar com a consultoria da FUNAI;

- o trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;

- devem ser admitidos o ingresso, o trânsito e a permanência de não índios no restante da área da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela FUNAI;

- o ingresso, o trânsito e a permanência de não índios não podem ser objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas;

- a cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público, tenham sido excluídos expressamente da homologação, ou não;

- as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade indígena ou pelos índios (art. 231, § 2.º, Constituição Federal, c/c art. 18, *caput*, Lei n. 6.001/1973);

- é vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas, a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa (art. 231, § 2.º, Constituição Federal, c/c art. 18, § 1.º, Lei n. 6.001/1973);

- as terras sob ocupação e posse dos grupos e das comunidades indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o disposto nos arts. 49, XVI, e 231, § 3.º, da CR/88, bem como a renda indígena (art. 43 da Lei n. 6.001/1973), gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos, taxas ou contribuições sobre uns ou outros;

- é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada;
- os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas são inalienáveis e indisponíveis (art. 231, § 4.º, CR/88);
- é assegurada a participação dos entes federados no procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, encravadas em seus territórios, observada a fase em que se encontrar o procedimento”.

Esse precedente, certamente, servirá de **paradigma** para tantos outros que tramitam na Corte, como as áreas indígenas **Parabure** (Mato Grosso — ACO 304) e **Kaigang** (Rio Grande do Sul — ACO 469) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**), bem como para questões já decididas, como aquela envolvendo a Reserva Indígena **Caramuru-Catarina Paraguassu** (etnia *Pataxó Hã-hã-hãe* — Bahia — ACO 312), **sem, contudo, como bem observou o Min. Barroso, vincular esses e outros tantos julgamentos.** [99](#)

■ 19.10.8. Defesa judicial dos direitos e interesses dos índios

■ 19.10.8.1. *Legitimidade ativa: índios, comunidades, organizações e o MP (Federal ou Estadual)*

Estabelece o art. 232 que os **índios**, suas **comunidades** e **organizações** são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, **intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.**

Relevante a previsão da possibilidade de o *índio* portar em juízo o interesse de toda a comunidade, em verdadeira representação ideológica e proteção de direito comunitário ou coletivo, indisponível e de ordem pública.

Essa ideia, reconhece José Afonso da Silva, “... reconduz à comunidade de direito que existia no seio da gentilidade. ‘Os bens da *gens* pertenciam conjuntamente a todos os gentílicos. E este direito se distinguia do de cada um em particular, por não ser exclusivo, mas indiviso e inalienável e indissolúvelmente ligado à qualidade de membro da coletividade’”. [100](#)

Por fim, no tocante ao **MP**, a referida instituição tanto figurará como interveniente e fiscal da lei (de modo mais abrangente, o art. 179, *caput*, do CPC/2015, fala em “fiscal da **ordem jurídica**”) e dos interesses dos indígenas como poderá ser legitimada ativa.

O art. 129, V, estabelece ser **função institucional do Ministério Público** a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas, podendo atuar tanto o MP Federal como o Estadual, de acordo com a competência da Justiça Federal ou Estadual.

■ **19.10.8.2. Competência: Justiça Federal x Justiça Estadual**

Aos **juízes federais** compete processar e julgar a **disputa sobre direitos indígenas** (art. 109, XI).

A grande questão é como interpretar a amplitude da expressão *disputa sobre direitos indígenas*.

A posição do STF é no sentido de estabelecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que versem sobre questões ligadas diretamente:

- à cultura indígena;
- aos direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;
- **a interesses constitucionalmente atribuíveis à União, como as infrações praticadas em detrimento de bens e interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas.**

Para se caracterizar a competência criminal da Justiça Federal, os crimes devem estar relacionados à disputa sobre direitos indígenas (art. 109, IV e XI).

Na hipótese de crime praticado por índio contra outro índio, mesmo que dentro do aldeamento indígena, e desde que não tenha nenhuma relação com *disputa sobre direitos indígenas*, a competência será da **Justiça Estadual**.

Para exemplificar, destacamos o boletim *Notícias do STF* (03.08.2006), que relata os fatos narrados no RE 419.528: “no caso sob análise, a Polícia Civil do

Estado do Paraná instaurou inquérito para investigar a prática dos crimes de ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal e/ou tentativa de homicídio atribuídos a três índios contra uma menina de 15 anos, também de origem indígena. Os crimes supostamente ocorreram no trajeto entre o Posto Indígena Queimadas, onde morava a índia e sua família, e Ortigueira, município no interior do Estado”.

No referido julgado, o Min. relator Cezar Peluso abriu divergência (o julgamento foi 6 x 4) e estabeleceu que “... os crimes praticados por e contra silvícolas isoladamente e que não configuram disputa sobre direitos indígenas devem ser julgados pela Justiça comum”, afastando-se a competência da Justiça Federal, tudo conforme a ementa:

“Competência criminal. Conflito. Crime praticado por silvícolas, contra outro índio, no interior de reserva indígena. Disputa sobre direitos indígenas como motivação do delito. Inexistência. Feito da competência da Justiça Comum. Recurso improvido. Votos vencidos. Precedentes. Exame. Inteligência do art. 109, incs. IV e XI, da CF. A competência penal da Justiça Federal, objeto do alcance do disposto no art. 109, XI, da Constituição da República, só se desata quando a acusação for de **genocídio**, ou quando, na ocasião ou motivação de outro delito de que seja índio o agente ou a vítima, tenha havido **disputa sobre direitos indígenas**, não bastando seja aquele imputado a silvícola, nem que este lhe seja vítima e, tampouco, que haja sido praticado dentro de reserva indígena” (RE 419.528, Rel. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, j. 03.08.2006, DJ de 09.03.2007).[101](#)

■ 19.10.9. Educação nas comunidades indígenas

O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às *comunidades indígenas* **também** a *utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem* (art. 210, § 2.º).

A utilização da expressão “também” confere a ideia de **complementaridade**, ou seja, no tocante às comunidades indígenas, não se podem adotar processos de aprendizagem somente na língua portuguesa; em igual medida, está vedada a

utilização de processos que utilizem somente as línguas maternas e processos próprios de aprendizagem dos índios.

O ensino tem de ser transmitido por meio de ambos os instrumentos. O acréscimo dos mecanismos próprios dos índios fortalece a ideia de preservação dos seus costumes, línguas, crenças e tradições, indispensável em razão da inegável diferença cultural entre o homem civilizado e a comunidade indígena.

Assegura-se, assim, para as comunidades indígenas, uma **educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue**.

Nos termos do *Decreto n. 26/91*, ficou atribuída ao **Ministério da Educação** a competência para coordenar as ações referentes à educação indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a *FUNAI*, sendo referidas ações desenvolvidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da Educação.

Por sua vez, o art. 78 da Lei n. 9.394/96 (*Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*) dispõe caber ao **Sistema de Ensino da União**, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:

- **proporcionar** aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências;
- **garantir** aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas.

Todo esse processo e as conquistas contempladas no texto de 1988 contribuíram para assegurar as especificidades culturais dos indígenas, garantindo a preservação das comunidades e a valorização dessa cultura, como se percebe pelo diagnóstico feito pelo *Plano Nacional de Educação*, aprovado pela Lei n. 10.172/2001, e que pedimos vênha para transcrever:

“No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização e integração forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao ensino bilíngue, a tônica foi uma só: **negar a diferença**, assimilar os índios, fazer com que eles se transformassem em algo diferente do que eram. Nesse processo, a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de instrumento de **imposição de valores alheios e negação de identidades e culturas diferenciadas**. Só em anos recentes esse quadro começou a **mudar**. Grupos organizados da sociedade civil passaram a trabalhar junto com comunidades indígenas, buscando alternativas à submissão desses grupos, como a garantia de seus territórios e formas menos violentas de relacionamento e convivência entre essas populações e outros segmentos da sociedade nacional. A escola entre grupos indígenas ganhou, então, um **novo significado** e um **novo sentido**, como meio para assegurar o acesso a conhecimentos gerais sem precisar negar as especificidades culturais e a identidade daqueles grupos. Diferentes experiências surgiram em várias regiões do Brasil, construindo projetos educacionais específicos à realidade sociocultural e histórica de determinados grupos indígenas, praticando a **interculturalidade** e o **bilíngüismo** e adequando-se ao seu **projeto de futuro**” (item III, 9.1, do Anexo da referida lei — original sem grifos).

Essa tendência está adequada aos ditames fixados no art. 215, § 1.º, que delega ao Estado o dever de proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

■ 19.10.10. Infanticídio indígena

Tema de grande importância vem tomando a pauta do parlamento. Discute-se se seria possível preservar práticas ainda observadas de **infanticídio indígena** dentro de uma ideia de preservação dos costumes, crenças e tradições, na forma do art. 231, *caput*, ou se, por outro lado, haveria afronta à proteção do direito à vida, também estabelecido na Constituição.

Existe projeto de lei tramitando para a criminalização da prática (vide **PL n. 1.057/2007-CD — “Lei Muwaji”** — nome dado em homenagem a uma mãe da tribo dos suruwahas, que enfrentou a tradição de seu povo e salvou a vida de sua filha que nasceu com uma dita “deficiência”). Em nossa opinião, a prática não se mostra mais adequada, inclusive com os tratados internacionais assinados pelo Brasil e, nesse sentido, louvamos o importante trabalho que vem sendo desenvolvido pela organização não governamental *ATINI — Voz pela Vida*.

Para **ilustrar o tema e provocar o debate**, transcrevemos parte do discurso proferido pelo Deputado Federal Lincoln Portela (19.09.2007 — Câmara dos Deputados):

“a revista *Veja*, na edição de 15 de agosto deste ano, publicou reportagem chocante, mostrando que, no mínimo, 13 etnias o conservam (o infanticídio indígena, acrescente-se). Entre essas, a dos ianomâmis, responsáveis pela morte de 201 das suas crianças, de 2004 a 2006, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde.

Na mesma reportagem, é narrada a comovente história da menina Hakani, nascida em 1995, na tribo dos suruarrás, que vivem semi-isolados no sul do Amazonas. Ela foi condenada à morte, aos 2 anos de idade, por não apresentar desenvolvimento compatível com sua faixa etária. Os pais, designados para cumprir a sentença, preferiram o suicídio. Em lugar deles, o irmão mais velho e o avô, pressionados sucessivamente, tentaram, porém não conseguiram levá-la a termo.

Apesar dos ferimentos provocados por essas duas tentativas, a pequena Hakani sobreviveu. Entretanto, passou a ser tratada como um bicho: vivia ao relento e se alimentava das sobras que encontrava pelo chão. Tamanho sofrimento durou cerca de 3 anos, até o casal de missionários Márcia e Edson Suzuki receber permissão da tribo para levá-la ao hospital.

Logo em seguida, eles iniciaram o processo legal de adoção. Mas precisaram aguardar 5 longos anos pela autorização judicial, pois, por incrível que pareça, foram acusados por um antropólogo do Ministério Público de prejudicar ‘uma prática cultural repleta de significados’ para os suruarrá, quando impediram o assassinato da menina.

Felizmente, o Juiz não se deixou impressionar por essa argumentação esdrúxula. Assim, embora ainda inspire cuidados, devido às sequelas da enorme crueldade a que foi submetida, Hakani pode contar agora com a proteção integral de seus pais adotivos.

Em muitos casos, porém, as crianças indígenas julgadas indesejáveis pelas respectivas comunidades não têm a mesma sorte. Quando nascem com algum problema físico ou mental, ou do sexo feminino, ao contrário do esperado pela família, ou gêmeas, ou até filhas de mães solteiras, podem acabar sacrificadas, envenenadas ou enterradas vivas, nessa terrível versão nacional da matança dos inocentes” (*Sessão: 247.1.53.O, site da Câmara dos Deputados*).

Vamos aguardar a votação da matéria pelas Casas Legislativas. Não temos conhecimento de pronunciamento judicial sobre o tema (pendente).

■ 19.11. QUESTÕES

1. (MPT/2006) Quanto à ordem social, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições;
- b) a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, na forma da lei, propiciando-lhe os bens materiais necessários para uma vida digna;
- c) o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- d) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações e, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, dentre outras atribuições, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

e) não respondida.

2. (DP SP 2007 FCC) A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que

- a) são destinatários dos direitos e garantias fundamentais os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, daí a proibição de extradição de brasileiros natos e naturalizados em qualquer circunstância.
- b) o direito fundamental à tutela jurisdicional se confunde com o direito de petição, eis que em ambos os casos exige-se a comprovação de um gravame pessoal ou uma lesão de direitos.
- c) a seguridade social deva garantir um salário mínimo de benefício previdenciário mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência ou tê-la provida.
- d) é dever do estado o oferecimento de ensino fundamental e médio obrigatórios e gratuitos a todos e a progressiva universalização do ensino superior.
- e) a previdência social se organiza sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, já a assistência social é endereçada a todos os que dela necessitarem independentemente de contribuição à seguridade social.

3. (TJ SP 2007) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público determinadas incumbências. Indique a afirmativa incorreta:

- a) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
- b) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
- c) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
- d) obrigar o poluidor a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, desde que comprovada a existência de culpa.

4. (DP SP 2006 FCC) Norma Técnica do Ministério da Saúde para Tratamento dos

Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes prevê a possibilidade da contracepção de emergência. Referida norma é

- a) constitucional, considerando que no sistema federativo brasileiro compete privativamente à união legislar sobre a saúde da mulher.
- b) constitucional, já que no âmbito da competência concorrente para legislar sobre o direito à saúde a união editou, através da norma técnica, apenas normas gerais.
- c) inconstitucional, já que a constituição federal de 1988 não tratou dos direitos sexuais e reprodutivos.
- d) inconstitucional, uma vez que na federação brasileira somente o município poderia tratar da matéria.
- e) constitucional, uma vez que torna eficaz o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e permite o exercício do direito constitucional do planejamento familiar.

5. (MPU 2007 FCC) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com relação ao meio ambiente é correta a afirmação:

- a) As usinas que operem com reatores nucleares deverão ter sua localização definida em lei estadual ou municipal, podendo ocorrer uma pré-instalação.
- b) A Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense não são considerados patrimônio nacional pela Constituição Federal brasileira.
- c) As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores à sanção penal, que será dependente da obrigação de reparar os danos causados.
- d) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
- e) A Serra do Mar e a Zona Costeira não são consideradas patrimônio nacional pela Constituição Federal brasileira.

6. (AGU-Proc. Federal 2007 CESPE UnB)

A demarcação de terras indígenas tem, entre outras, a função de criar uma nova delimitação espacial da titularidade indígena, tendo características de ato constitutivo.

7. (AGU-Proc. Federal 2007 CESPE UnB)

Caso uma comissão parlamentar de inquérito com funcionamento em Brasília intime um indígena, que mora no estado de Mato Grosso, a prestar depoimento na condição de

testemunha, no DF, haverá violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas, uma vez que a intimação do indígena configuraria, em tese, constrangimento à sua liberdade de locomoção, por ser vedada pela CF a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nas hipóteses constitucionalmente elencadas.

8. (AGU-Proc. Federal 2007 CESPE UnB)

A CF, ao assegurar aos índios direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, foi coerente com a tradição do direito indigenista que consagrou o indigenato, ou seja, o instituto jurídico por meio do qual se reconhece, no Brasil, o direito dos índios sobre as terras que ocupam, independentemente de título aquisitivo, nos mesmos moldes do sistema romanístico da posse e da propriedade, previsto pela legislação civil.

9. (PGE DF 2007 ESAF) No atinente à ordem social, à seguridade social, à saúde, à previdência e à assistência social, à educação e ao meio ambiente, assinale a opção correta.

- a) O constituinte originário dedicou especial proteção a certos ecossistemas, como a Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense, motivo pelo qual impediu que fossem objeto de exploração econômica.
- b) Sempre que algum órgão federal, aí incluído o Ministério Público Federal, detectar malversação ou apropriação ilícita de fundos do Sistema Único de Saúde, a competência para julgar o ilícito será da Justiça Federal, uma vez que o financiamento desse sistema compete, por completo, à União.
- c) As normas constitucionais pertinentes à proteção do ambiente têm caráter eminentemente negativo, no sentido de que impõem proibições à ação estatal.
- d) Considere a seguinte situação hipotética. A Câmara Legislativa aprovou projeto de lei segundo o qual seria prescindível realizar estudo prévio de impacto ambiental para determinados empreendimentos industriais a serem implantados em áreas de cerrado do DF. Recebido o projeto pelo governador para sanção, caberia à PRG-DF recomendar-lhe o veto, pois o ente federado não pode aprovar normas desse teor, ainda que com base em sua autonomia legislativa.
- e) Por força do direito fundamental, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado, a adesão ao plano estatal de previdência oficial é eminentemente voluntária.

10. (PGE RR 2006 FCC) Dentre os princípios constitucionais da seguridade social encontra-se o princípio:

- a) da proporcionalidade do valor dos benefícios.
- b) da individualidade da cobertura e do atendimento.
- c) do caráter contributivo dos benefícios, serviços e cobertura.
- d) do caráter democrático e descentralizado, mediante gestão tripartite nos órgãos colegiados.
- e) da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

11. (TJ MG 2007-EJEF) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia:

- a) do atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
- b) da aplicação, anualmente, pela União, de, no mínimo, quinze, e pelos Estados, de vinte por cento da receita resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- c) da oferta de ensino diurno regular, adequado às condições do educando.
- d) da progressiva universalização do ensino médio gratuito.

12. (TJ SP 2007) Assinale a alternativa incorreta.

- a) O direito à proteção, à vida e à saúde se dá mediante a efetivação de políticas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento, em condições dignas de existência.
- b) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros.
- c) A colocação da criança ou adolescente em família substituta estrangeira far-se-á nas modalidades de tutela e adoção.
- d) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

13. (Acadepol 2007 PR) Quanto à proteção constitucional da família, da criança, do adolescente e do idoso, assinale a alternativa correta.

- a) Aos maiores de 60 (sessenta) anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
- b) Entende-se como entidade familiar, para fins de proteção do Estado, a comunidade formada pela mãe solteira que adota um filho.

- c) A idade mínima para admissão ao trabalho é de doze anos completos para a condição de aprendiz e de catorze anos completos para o trabalho normal, exceto trabalho noturno, insalubre ou perigoso, cuja idade mínima é de 18 anos.
- d) Como medida preventiva ao tráfico ilícito de menores, é vedada a adoção de criança brasileira por estrangeiros domiciliados no exterior.
- e) São penalmente inimputáveis os menores de dezesesseis anos.

14. (Acadepol 2007 PR) De acordo com a redação do artigo 193 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a ordem social tem como base:

- a) a defesa da propriedade privada, da livre concorrência e do consumidor, e como objetivo a preservação do meio ambiente sadio e equilibrado.
- b) a defesa do consumidor, e como objetivo a preservação do meio ambiente sadio e equilibrado.
- c) a defesa dos direitos e garantias individuais do cidadão, e como objetivo a preservação ambiental.
- d) a propriedade privada e a livre concorrência, e como objetivo a defesa do consumidor.
- e) o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

15. (TJ-MG/EJEF/2008) A Constituição da República dedica um capítulo especial à família, à criança, ao adolescente e ao idoso e especifica normas de aplicabilidade imediata e outras dirigidas ao legislador ordinário.

- a) A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, vedada sua efetivação por estrangeiro.
- b) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
- c) Os idosos, mesmo após 65 anos de idade, não têm direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos.
- d) O planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, é disciplinado somente pelo Estado, vedada a livre decisão do casal.

16. (Magistratura-RR/FCC/2008) Sobre a aplicação de recursos públicos na educação, estabelece a Constituição da República que:

- a) União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicarão, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

- b) a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios será considerada receita do governo federal, para efeito do cálculo do mínimo constitucional de destinação de recursos para a educação.
- c) as cotas estaduais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica na respectiva rede de ensino.
- d) os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sendo vedada, contudo, sua destinação a bolsas de estudos.
- e) a distribuição de recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional da educação, a ser definido por Decreto do Presidente da República, de duração trienal.

17. (MPE/PE/FCC/2008) Tendo em vista os aspectos constitucionais relativos à necessidade de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é correto afirmar que

- a) a Serra do Mar Paulista, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira de Pernambuco, entre outras, são patrimônios estaduais e sua utilização far-se-á livremente, na forma da lei dos respectivos Estados.
- b) as usinas que operem com reator nuclear devem ter sua localização definida em lei do município, por ser este o titular exclusivo do interesse local, sem o que não poderá ser instalada.
- c) a edição de uma lei estadual, a exemplo daquela que autorize ou regulamente a realização de “briga de galo”, é considerada inconstitucional, em razão das regras norteadoras do meio ambiente.
- d) as terras devolutas ou as arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, são disponíveis e dispensam sua desafetação pelo Poder Público em geral.
- e) incumbe ao Poder Público federal, com exclusividade, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

18. (MPE/PR/2008) Analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta:

- I. a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial;
- II. a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de

contribuição à seguridade social;

III. a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

IV. o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais;

V. o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

a) todas as assertivas estão corretas;

b) apenas a assertiva I está incorreta;

c) apenas a assertiva II está incorreta;

d) apenas a assertiva III está incorreta;

e) apenas as assertivas IV e V estão incorretas.

19. (TRT 8.^a Reg. 2008) Sobre a ordem social, no tocante aos índios, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, inclusive na condição de assistente litisconsorcial, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

b) São nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação das terras indígenas, não gerando essa nulidade nenhum direito de indenização ou ação contra a União.

c) Lei complementar poderá disciplinar organização de atividade garimpeira em cooperativa, que tem prioridade na concessão de pesquisa e lavra, garantindo-se essa atividade inclusive em terras indígenas, desde que com autorização do Congresso Nacional, assegurando-se aos índios participação nos resultados da lavra.

d) As terras indígenas destinam-se a posse permanente dos índios, cabendo-lhes o usufruto, concorrente com a União, das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

e) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, *ad referendum* do Congresso Nacional, no interesse da soberania do País, garantido o retorno imediato logo cesse a causa.

20. (AGU — CESPE/UnB 2010) No que se refere aos direitos e deveres das

populações indígenas, julgue o item abaixo:

No processo de demarcação de terra indígena situada em região de fronteira, o STF considera dispensável a manifestação do Conselho de Defesa Nacional no processo homologatório.

21. (Oficial de Defensoria Pública do Estado de SP/FCC/2010) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica e a Serra do Mar são consideradas, conforme norma expressa da Constituição Federal:

- a) bens de propriedade dos Estados onde se situem, que disciplinarão a utilização dos recursos naturais.
- b) bens de propriedade dos municípios onde se situem, vedada sua utilização por terceiros.
- c) patrimônio do ente público responsável pela sua gestão, utilização e preservação.
- d) patrimônio nacional, vedada, portanto, sua utilização pelos cidadãos.
- e) patrimônio nacional, passíveis de serem utilizados de forma sustentável.

22. (87.º concurso MP/SP) O financiamento do sistema único de saúde é feito com recursos dos orçamentos:

- a) da Seguridade Social e da União.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- c) dos Estados, dos Municípios, e da União.
- d) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- e) da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

23. (Procurador do Estado/MT — FCC/2011) Em capítulo dedicado à comunicação social, a Constituição da República veda:

- a) a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
- b) que haja o cancelamento da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, antes de vencido o prazo.
- c) alterações de controle societário nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, sem o prévio consentimento do Congresso Nacional.
- d) que se atribuam a gestão das atividades e o estabelecimento do conteúdo da programação de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens a

quem não seja brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos.

- e) a publicação de veículo impresso de comunicação sem a prévia licença de autoridade competente, nos termos da lei.

24. (Magistratura/PB — CESPE/UnB/2011) Relativamente à ordem social e aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta:

- a) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, desde que homologada a separação judicial do casal por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos.
- b) A CF consagrou o princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras, salvo, *ad referendum* do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, devendo, cessado o risco, os índios retornar, de imediato, às suas terras.
- c) A jurisprudência do STF reconhece que os estrangeiros, mesmo os não residentes no país, são destinatários dos direitos fundamentais consagrados pela CF, sem distinção de qualquer espécie em relação aos brasileiros. No mesmo sentido, as pessoas jurídicas são destinatárias dos direitos e garantias elencados na CF, na mesma proporção das pessoas físicas.
- d) São legitimados para impetrar mandado de segurança a pessoa física, nacional ou estrangeira, e a pessoa jurídica privada, mas não a pública, visto o mandado de segurança ter como função garantir direito líquido e certo contra ato de autoridade pública.
- e) A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do Mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira são considerados patrimônio nacional pela CF, razão pela qual é vedada a utilização dos recursos naturais existentes nessas áreas, ainda que sujeitas ao domínio privado.

25. (Analista Ambiental — MMA — CESPE/UnB/2011) Com relação à educação ambiental, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988, apesar de reconhecida por parte significativa da doutrina como avançada no campo dos direitos relacionados ao meio ambiente, não trata expressamente da educação ambiental.

26. (Promotor de Justiça/MS — MPE-MS/2011) Segundo a Constituição Federal, a ordem social tem como objetivo:

- a) a dignidade da pessoa humana;
- b) a prevalência dos direitos humanos;
- c) o bem-estar e a justiça sociais;
- d) a consecução do princípio da isonomia;
- e) os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa.

27. (Titular de Serviços de Notas e de Registros — TJ-CE — IESES/2011) NÃO figura entre os objetivos organizacionais da seguridade social previstos na Constituição da República:

- a) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- b) Universalidade da cobertura e do atendimento.
- c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- d) Unidade da base de financiamento.

28. (Magistratura — TRT1 — FCC/2012) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios:

- a) permitem-lhes o usufruto exclusivo das riquezas de solo, subsolo, rios e lagos nelas existentes.
- b) podem ser utilizadas para a atividade garimpeira, desde que em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico-social.
- c) geram o direito à propriedade à comunidade indígena que as habita, porém os direitos sobre elas prescrevem caso permaneçam abandonadas por mais de quinze anos.
- d) são, segundo disposição expressa da Constituição Federal, inalienáveis e indisponíveis.
- e) podem ser economicamente exploradas, desde que o Senado autorize, garantindo-se à comunidade indígena afetada a participação nos lucros obtidos com a exploração.

29. (Delegado de Polícia — UEG — PC/GO/2013) A Constituição Federal prevê a proteção do patrimônio cultural brasileiro, sua defesa, valorização e difusão. Esse patrimônio constitui-se pelos bens de natureza:

- a) imaterial, pertencentes às muitas etnias, consideradas naquilo que são portadoras de referências comuns entre si, capazes de integrar uma identidade e unicidade nacionais.
- b) material e imaterial portadores de referências à identidade e à memória das diversas

etnias, consideradas numa perspectiva multicultural.

- c) material e imaterial, portadores de referência do povo brasileiro, considerado em sua unidade, unicidade nacional e étnica.
- d) material pertencentes à história nacional dos povos colonizadores e que representam a unidade e a memória nacionais.

30. (Concurso Procurador da República/27.º — 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- a) o direito à liberdade de crença depende não apenas do direito de exprimir a crença, mas de uma autodeterminação existencial a partir dela;
- b) “deficiência” é um conceito em evolução, resultando da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
- c) o STF, a partir da Constituição de 1988, passou a enfrentar a questão de gênero sob perspectivas que ora desestabilizam o enfoque tradicional das relações entre homens e mulheres, abrindo novas possibilidades de conformações familiares, ora consolidando novas demandas das mulheres enquanto direitos fundamentais;
- d) a laicidade do Estado, tal como concebida pela Constituição de 1988, significa a adoção de uma perspectiva refratária à expressão pública da religiosidade por indivíduos e grupos.

31. (Defensor Público/AM — FCC/2013) A Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, prescrevendo ainda que:

- I. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
- II. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
- III. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Presidente da República, ouvidas as comunidades afetadas, que não

poderão participar nos resultados da lavra.

- IV. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, mas os direitos sobre elas são passíveis de prescrição, na forma da lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) III e IV.

32. (Escrivão da Polícia Federal — CESPE/UnB/2013) No que se refere à ordem social, julgue o item seguinte:

A CF reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam.

33. (Delegado de Polícia Federal — DPF — CESPE/UnB/2013) Considerando o disposto na CF acerca na ordem social, julgue os itens subsequentes:

- I. A floresta amazônica brasileira, assim como a mata atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne ao uso dos recursos naturais.
- II. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva.

34. (Defensor Público/DF — CESPE/UnB/2013) Relativamente às fontes de custeio da seguridade social, julgue o item abaixo:

A seguridade social tem como únicas fontes de custeio, além dos recursos advindos dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios, as contribuições do empregador e do trabalhador.

35. (Promotor de Justiça — MPSC — 2013) Analise o enunciado da questão abaixo e assinale “certo” ou “errado”:

As instituições privadas, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, observadas condições iguais de disputa com vistas à celebração dos indispensáveis

contratos de direito público ou convênios.

■ GABARITO ■

1. "b".
2. "e". Arts. 201 e 203 da CF/88.
3. "d". Art. 225, § 1.º, da CF/88.
4. "e".
5. "d".
6. "errado".
7. "certo".
8. "errado".
9. "d".
10. "e". Art. 194, parágrafo único, III, da CF/88.
11. "d". Art. 208, II, da CF/88.
12. "c".
13. "b". Art. 226, § 4.º, da CF/88.
14. "e". Art. 193 da CF/88.
15. "b". Art. 229 da CF/88.
16. "c". Art. 212, § 6.º, da CF/88.
17. "c". Confira parte teórica.

18. “a”.
19. “a”. Art. 232 da CF/88.
20. “certo”.
21. “e”.
22. “e”.
23. “d”, nos termos do art. 222, § 1.º, da CF/88.
24. “b”, nos termos do art. 231, § 5.º, da CF/88.
25. “errado”, por violar a literalidade do art. 225, § 1.º, VI, da CF/88.
26. “c”, nos termos do art. 193 da CF/88.
27. “d”, nos termos do art. 194 da CF/88.
28. “d”, cf. art. 231, § 4.º.
29. “b”, de acordo com o art. 216, <i>caput</i> , da CF/88.
30. “d”. Cf. aprofundamento no <i>item 3.10.1.3</i> .
31. “c”. Cf. art. 231, §§ 1.º ao 4.º
32. “errado”. Conforme estabelecemos na parte teórica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, apesar de consideradas bens da União (art. 20, XI), destinando-se à posse permanente dos silvícolas, são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Assim, o erro na questão está em afirmar que as terras que tradicionalmente ocupam são de propriedade dos índios.
33. O <i>item I</i> está “errado”, pois, de acordo com o art. 225, § 4.º, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional , e não bem da União. O <i>item II</i> está “certo” (arts. 20, XI, e 231, § 4.º).
34. “errado”, pois as indicadas não são as “únicas” fontes de custeio (cf. art. 195).

35. “errado”. A Constituição de 1988, depois de estabelecer que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, não estabelece condições iguais de disputa. Isso porque, de acordo com o art. 199, § 1.º, as instituições privadas poderão participar de **forma complementar** do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, **tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos**.

ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

■ 20.1. PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

■ 20.1.1. Evolução do Estado e a Ordem Econômica

Partindo da ideia de Estado de Direito, podemos identificar, segundo a doutrina, uma tríplice vertente: **liberal**, **social** e **pós-social**.

No **Estado Liberal** percebe-se uma evidenciação do **indivíduo**, delineando-se um Estado não intervencionista, dentro da perspectiva de “intervenção mínima”.

De acordo com Dallari, “o Estado Moderno nasceu absolutista e durante alguns séculos todos os defeitos e virtudes do monarca absoluto foram confundidos com as qualidades do Estado. Isso explica por que já no século XVIII o poder público era visto como inimigo da liberdade individual, e qualquer restrição ao individual em favor do coletivo era tida como ilegítima. Essa foi a raiz individualista do Estado Liberal. Ao mesmo tempo, a burguesia enriquecida, que já dispunha do poder econômico, preconizava a intervenção mínima do Estado na vida social, considerando a liberdade contratual um direito natural do indivíduo”.¹

Diante das novas necessidades sociais, surge a teorização do **Estado Social**, evidenciando-se o **grupo** e colocando a **questão social** como preocupação principal do Estado.

Norberto Bobbio assevera que a proteção dos **direitos sociais** requer uma atuação estatal, de forma **ativa**, diferente da solicitada (ou não solicitada) durante o Estado Liberal, produzindo tal organização dos serviços públicos, que teria sido a responsável pelo surgimento do próprio Estado Social.²

Uma das várias lições que podem ser extraídas da obra de Wilensky, e talvez a mais adequada ao tema aqui desenvolvido, consiste na verificação de que a **assistência** prestada pelo **Estado do bem-estar** (*Welfare State*), ou **Estado assistencial**, não é oferecida como caridade, mas sim como um **direito político**.³

Finalmente, o **Estado Pós-Social** (seguindo a classificação proposta por Campilongo), cujos atores sociais evidenciados são os novos movimentos sociais, sem, contudo, é claro, como pondera o autor, “... eliminar os problemas interindividuais nem ignorar a relevância da conflituosidade de classes...”.⁴

Com base nessa evolução, em um primeiro momento pode-se afirmar que os institutos clássicos do **direito de propriedade** e a **autonomia da vontade privada** eram **suficientes** para **regulamentar a atividade econômica**, até porque o capitalismo primitivo pregava a **autorregulação**, sem qualquer interferência do Estado na economia.

A partir do século XX, no entanto, a situação começa a ser repensada, especialmente diante das constantes situações de **abuso do poder econômico**.

Surge, então, “clima” propício para a **constitucionalização da economia**.

Nesse sentido, o art. 170, *caput*, da CF/88 estabelece que a **ordem econômica**, tendo por fim assegurar a todos existência **digna**, conforme os ditames da **justiça social**, funda-se em dois grandes **pilares**:

■ **valorização do trabalho humano;**

■ **livre-iniciativa.**

Cabe, aqui, observar que, nos termos do art. 1.º, IV, são **fundamentos** da República Federativa do Brasil:

■ **os valores sociais do trabalho;**

■ os valores sociais da livre-iniciativa.

O constituinte privilegia, portanto, o **modelo capitalista**, porém, não se pode esquecer da **finalidade** da ordem econômica, qual seja, assegurar a todos a **existência digna**, conforme os ditames da **justiça social**, afastando-se, assim, de um Estado absenteísta nos moldes do liberalismo.

Pelo contrário, o texto admite a **intervenção do Estado no domínio econômico**.

■ 20.1.2. Separação da Ordem Econômica e da Ordem Social

Conforme já estudamos no *capítulo 2*, a primeira Constituição brasileira a separar a *ordem econômica* da *ordem social* foi a de **1988**.

A ordem econômica recebeu tratamento sistemático, pioneiramente, na Constituição do México de 1917. No Brasil, sob a influência da *Constituição de Weimar*, de 1919, a primeira a tratar da ordem econômica e da ordem social em título único (Título IV) foi a de **1934**.

A Constituição de 1937, embora mantendo as matérias sobre a ordem econômica e social, aboliu a utilização de títulos e passou a destacar, de modo simplificado, a ordem econômica.

As Constituições de 1946, 1967 e a EC n. 1/69 seguiram a mesma estrutura da de 1934, agregando a ordem econômica e a ordem social em um único título.

A Constituição de 1988, conforme visto, inova e passa a tratar da ordem social em título próprio, **desvinculando-a** da ordem econômica, que, por sua vez, recebe matérias sobre o sistema financeiro nacional (Título VII). Alguns temas da ordem social que eram assegurados nas Constituições anteriores, como os *direitos dos trabalhadores*, foram deslocados para o Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais (direitos sociais).

■ 20.1.3. Meios de atuação do Estado

O Estado pode interferir na ordem econômica de modo **direto** ou **indireto**.

Quando se fala em atuação **direta**, o próprio Estado atua na economia de um país, seja em regime de **monopólio**, seja no de **participação** com as empresas do setor privado.

Já quanto à atuação **indireta**, o Estado busca fazer prevalecer o princípio da *livre concorrência* e evitar abusos como os decorrentes de cartéis, *dumping* etc.

■ 20.1.4. Princípios da Ordem Econômica



■ 20.1.4.1. Soberania nacional

A soberania é **fundamento** da República Federativa do Brasil (art. 1.º, I) e, ao ser prevista como *princípio da ordem econômica*, visa evitar a influência descontrolada de outros países em nossa economia.

No fundo, garante-se a ideia de **independência nacional**.

Isso não significa uma blindagem na economia em relação ao capital estrangeiro. Nos termos do art. 172, a lei disciplinará, com base no **interesse nacional**, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

Como bem anotam David Araujo e Vidal Serrano, “... os contratos e ajustes internacionais, de modo geral, devem pautar-se pela observância das normas de ordem pública e aquelas inerentes à autonomia decisória do país. Assim, padeceria de inconstitucionalidade um tratado que, por exemplo, submetesse o País compulsoriamente a decisões econômicas de uma instituição ou organismo internacional”.⁵

■ 20.1.4.2. *Propriedade privada e sua função social*

Ao instituir a propriedade privada como princípio da ordem econômica, o constituinte assegurou a **propriedade privada dos meios de produção**.

O direito de propriedade aparece como direito fundamental (art. 5.º, XXII); porém a propriedade terá de atender a sua **função social** (art. 5.º, XXIII), situação essa que se desdobra no âmbito da *política urbana* (arts. 182 e 183), no âmbito da *política agrícola e fundiária*, bem como da *reforma agrária* (arts. 184 a 191).

■ 20.1.4.3. *Livre concorrência*

Como desdobramento da **livre-iniciativa**, a **livre concorrência** aparece como princípio da Ordem Econômica, devendo ser balizada pelos ditames da **justiça social** e da **dignidade**.

Por esse motivo, não podemos considerá-la um bem em si e de modo absoluto, devendo o Estado refutar qualquer abuso.

O art. 173, § 4.º, dispõe que a lei **reprimirá** o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

De acordo com o art. 173, § 5.º, a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Nesse sentido, destacamos a **Lei n. 12.529/2011**, que, dentre outras providências, estrutura o **Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência — SBDC** e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos seguintes ditames constitucionais:

- **liberdade de iniciativa;**
- **livre concorrência;**
- **função social da propriedade;**
- **defesa dos consumidores;**
- **repressão ao abuso do poder econômico.**

O **SBDC** é formado pelo **Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE** (autarquia federal) e pela **Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda**.

■ **20.1.4.4. Defesa do consumidor**

Estamos diante da consagração, nas relações de consumo, do **princípio da vulnerabilidade**, tendo o constituinte considerado que o consumidor é a parte mais fraca da relação.

Cumprе observar que, nos termos do art. 5.º, XXXII, a **defesa do consumidor** é direito fundamental.

A proteção ao consumidor se implementa, dentre tantos instrumentos, pelo CDC (Lei n. 8.078/90) e, apenas para recordar, o STF entendeu a sua aplicação nas relações entre instituições financeiras e seus usuários:

“... As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. ‘Consumidor’, para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. Ação direta julgada improcedente” (ADI 2.591-ED, Rel. Min. Eros Grau, j. 14.12.2006, *DJ* de 13.04.2007 — cf. *item 14.10.19*).

■ 20.1.4.5. Defesa do meio ambiente

Mesmo que haja produção de riquezas, a atividade econômica deve estar orientada à proteção e defesa do meio ambiente.

Trata-se da ideia, já analisada (*item 19.8*), do **desenvolvimento sustentável**.

De acordo com o art. 225, *caput*, todos têm direito ao meio ambiente **ecologicamente equilibrado**, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A **EC n. 42/2003**, ao dar nova redação ao art. 170, VI, estabeleceu, na defesa do meio ambiente, a **possibilidade de tratamento diferenciado** conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, e de seus processos de elaboração e prestação.

Assim, parece razoável que o Estado ofereça, por exemplo, incentivos mediante isenções, benefícios fiscais etc., para as empresas que trabalhem com produtos recicláveis ou que produzam baixo impacto ambiental, ou seja, as empresas “ecologicamente corretas”.

■ 20.1.4.6. Redução das desigualdades regionais e sociais

Confirma-se a constante busca pela consagração do **Estado do bem-estar social**.

De acordo com o art. 3.º, III, é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Esse princípio é implementado por diversos instrumentos, como a criação de **regiões administrativas** (art. 43), a lei que institui o **plano plurianual** (art. 165, § 1.º), a possibilidade de **concessão de incentivos fiscais** na forma do art. 151, I, o **fundo de erradicação da pobreza**, que teve o seu prazo prorrogado por *tempo indeterminado* nos termos da **EC n. 67, de 22.12.2010** etc.

■ 20.1.4.7. *Busca do pleno emprego*

Dentro desse contexto, a busca do pleno emprego também aparece como princípio da ordem econômica, consagrando a perspectiva de **valorização do trabalho humano** e se materializando, também, como **princípio diretivo da economia**.

■ 20.1.4.8. *Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte*

Mostra-se bastante razoável atrelar a **livre concorrência** ao princípio da **igualdade** em sua vertente substancial e, como desdobramento, a possibilidade de tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

É o que prescreve o art. 179: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às **microempresas** e às **empresas de pequeno porte**, assim definidas em lei, **tratamento jurídico diferenciado**, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

■ 20.2. MONOPÓLIO DOS CORREIOS

Em 14.11.2003, a Associação Brasileira das Empresas de Distribuição (Abraed) propôs a **ADPF 46**, com pedido de liminar, contra a *Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT*, questionando a existência de monopólio constitucional de entrega de correspondências.

A principal questão que se discutia era em relação à possibilidade do trabalho das *empresas de distribuição*, criadas em grande número pelo País, com o objetivo de atender à demanda de logística, implementando, por consequência, a entrega de encomendas.

Isso porque, justificando o cabimento da ação, alegavam que os Correios ajuizaram várias ações sustentando o monopólio postal, inclusive objetivando a

aplicação das sanções criminais previstas na **Lei n. 6.538/78**.

Dentre os argumentos levantados pela Autora, destacam-se:

- o fundamento da livre-iniciativa (art. 1.º, IV);
- o livre-exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão (art. 5.º, XIII);
- a livre concorrência (art. 170, IV);
- a inexistência de monopólio constitucional postal, já que não se encontra a suposta exceção enumerada no art. 177.

A Constituição, de fato, estabelece regras sobre o **serviço postal** em dois dispositivos:

- **Art. 21, X** — “competete à União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional”;
- **Art. 22, V** — “competete privativamente à União legislar sobre serviço postal”.

Por sua vez, a Lei n. 6.538/78, em seu art. 9.º, dispõe que são exploradas pela União, em **regime de monopólio**, as seguintes atividades postais:

- recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de **carta** e cartão-postal;
- recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de correspondência agrupada;
- fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas de franqueamento postal.

O art. 47 da lei define **carta** como o “objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário”.

E o art. 42 da mesma lei diz ser *crime de violação do privilégio postal da União*: “coletar, transportar, transmitir ou distribuir, sem observância das

condições legais, objetos de qualquer natureza sujeitos ao **monopólio da União**, ainda que pagas as tarifas postais ou de telegramas. Pena: detenção, até 2 meses, ou pagamento não excedente a dez dias-multa”.

Finalmente, em **05.08.2009**, o STF, por 6 x 4, julgou **improcedente** a **ADPF 46** e, assim, reconheceu a recepção dos dispositivos da lei e, nesse sentido, o **monopólio dos Correios para as correspondências pessoais**.[6](#)

Segundo informado, “prevaleceu o voto do Min. Eros Grau, que, tendo em conta a orientação fixada pelo Supremo na *ACO 765 QO/RJ*, no sentido de que o **serviço postal** constitui **serviço público**, portanto, não atividade econômica em sentido estrito, considerou inócua a argumentação em torno da ofensa aos princípios da livre-iniciativa e da livre concorrência. Distinguindo o regime de privilégio de que se reveste a prestação dos serviços públicos do regime de monopólio, afirmou que os **regimes jurídicos** sob os quais são prestados os **serviços públicos** implicam que sua prestação seja desenvolvida sob **privilégios**, inclusive, em regra, o da **exclusividade** na **exploração da atividade econômica em sentido amplo** a que corresponde essa prestação, haja vista que exatamente a potencialidade desse privilégio incentiva a prestação do serviço público pelo setor privado quando este atua na condição de concessionário ou permissionário. Asseverou que a prestação do serviço postal por empresa privada só seria possível se a CF afirmasse que o serviço postal é livre à iniciativa privada, tal como o fez em relação à **saúde** e à **educação**, que são **serviços públicos**, os quais podem ser prestados independentemente de concessão ou permissão por estarem excluídos da regra do art. 175, em razão do disposto nos artigos 199 e 209”.

E continua: “ressaltou o Min. Eros Grau que o serviço postal é prestado pela ECT, **empresa pública** criada pelo Decreto-lei n. 509/69, que foi recebido pela CF/88, a qual deve atuar em regime de **exclusividade** (em linguagem técnica, em situação de privilégio, e, em linguagem corrente, em regime de monopólio), estando o âmbito do serviço postal bem delineado nos artigos 7.º e seguintes da Lei 6.538/78, também recebida pela CF/88. Por fim, julgando insuficiente a atuação subsidiária do Estado para solução dos conflitos da realidade nacional,

considerou que, vigentes os artigos 1.º e 3.º da CF, haver-se-ia de exigir um Estado forte e apto a garantir a todos uma existência digna, sendo incompatível com a Constituição a proposta de substituição do Estado pela sociedade civil. Nesta assentada, o **Min. Carlos Britto** apresentou esclarecimentos sobre seu voto, afirmando **excluir do conceito de serviço postal apenas a entrega de encomendas e impressos**. Concluiu, assim, pela improcedência do pedido. Quanto a essa parte, ficaram vencidos o Min. Marco Aurélio, relator, que julgava procedente o pleito e os Ministros Gilmar Mendes, Presidente, que reajustou o voto proferido na assentada anterior, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, os quais o julgavam parcialmente procedente, para fixar a interpretação de que a prestação exclusiva pela União da atividade postal limitar-se-ia ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada, nos termos do art. 9.º da Lei 6.538/78, não abrangendo a distribuição de boletos (v.g. boletos bancários, contas de água, telefone, luz), jornais, livros, periódicos ou outros tipos de encomendas ou impressos. O Tribunal, por unanimidade, ainda deu interpretação conforme ao art. 42 da Lei 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9.º do referido diploma legal” (ADPF 46/DF, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Eros Grau, 3 e 5.8.2008).

Finalmente, destacamos dois importantes julgados reconhecendo a **imunidade tributária da ECT relativamente ao ICMS e ao IPVA** e que pedimos vênia para transcrever:

“EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. **ICMS**. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica.

2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza

pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de **exclusividade** pela ECT.

3. Nos autos do **RE n. 601.392/PR**, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que **a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio.**

4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos.

5. Não há comprometimento do *status* de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui *conditio sine qua non* para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos.

6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária.

7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas” (**RE 627.051**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.11.2014, Pleno, *DJE* de 11.02.2015).

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. **IPVA.**

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que **a imunidade recíproca deve ser reconhecida em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ainda que o patrimônio, renda ou serviço desempenhado pela Entidade não esteja necessariamente relacionado ao privilégio postal.**

2. Especificamente com relação ao IPVA, cumpre reafirmar o quanto assentado na **ACO 789/PI**, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião na qual foi confirmada a outorga da imunidade recíproca para o fim de afastar a incidência sobre os veículos de propriedade da requerente.

3. Ação Cível Originária julgada procedente” (**ACO 879**, Rel. Min. Marco

Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, j. 26.11.2014, *DJE* de 10.02.2015).

■ 20.3. QUEBRA DO MONOPÓLIO DA UNIÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS PARA A PESQUISA E USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, BEM COMO SOBRE A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA (EC N. 49/2006)

Segundo o **Parecer n. 767/2003-CCJ**, do relator Senador José Jorge, a *PEC n. 7/2003* (que originou a **EC n. 49/2006**, em análise), “... tem por objeto ampliar o acesso dos serviços de medicina nuclear aos radioisótopos de meia-vida curta (2 a 120 minutos). Esses produtos são utilizados como marcadores em exames de imagem, como a tomografia por emissão de pósitrons (PET) e de fótons simples (Spect)” (*DSF* de 12.07.2003, p. 17.877-8).

A Assembleia Nacional Constituinte de 1988, à época, entendeu mais conveniente, tendo em vista o temor gerado por eventual uso indevido da **tecnologia nuclear** (que viria a ser confirmado nas tragédias de Chernobyl e Goiânia), determinar o monopólio da União, nos termos do art. 177, V, da CF/88, sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.

Agora, com a regra trazida pela **EC n. 49/2006**, foi aberta a possibilidade de produção, comercialização e utilização de **radioisótopos**, podendo ser autorizadas sob o **regime de permissão**, conforme as alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do **caput** do art. 21 da Constituição Federal.

Assim, enquanto novos princípios e condições em relação à exploração dos serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, surgem duas importantes novas regras (art. 21, XXIII, “b” e “c”):

■ sob **regime de permissão**, são autorizadas a comercialização e a utilização de **radioisótopos** para a pesquisa e usos **médicos**, **agrícolas** e **industriais**;

■ sob **regime de permissão**, são autorizadas a **produção**,

comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas.

A nova regra, assim, segundo a Senadora Ideli Salvatti, tem por objetivo “... flexibilizar o monopólio da União para casos muito específicos. Tendo em vista a nossa inovação tecnológica com o advento da tomografia por emissão de pósitrons e da tomografia por emissão de fótons simples, há necessidade de que essa flexibilização tenha obrigatoriamente que ocorrer, porque esses radioisótopos utilizados nesses dois tipos de câmaras são emissores de partículas de meia-vida muito curta. Alguns duram apenas poucos minutos e outros, no máximo, duas horas. Portanto, não é possível que o deslocamento desse tipo de produto se dê em distâncias longas, porque, senão, o material perde a eficiência e a capacidade de ser utilizado nessa maravilha de evolução que é a medicina nuclear” (*DSF* de 22.10.2003, p. 33025).

É importante notar que a instituição do **regime de permissão** garantirá o necessário **controle** da referida atividade nuclear pelo Poder Público.

Como bem observou o então Senador José Jorge, no parecer da CCJ, “ainda assim, é imperioso que a **Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) exerça controle rigoroso sobre a produção, comercialização e utilização desses materiais**. Para facilitar a atuação da Comissão, a PEC propõe que apenas o regime de permissão seja utilizado para admitir a participação de entes que não a União na área de materiais radioativos, eliminando o regime de concessão. Dessa forma, a CNEN terá maior facilidade em revogar o contrato quando julgar necessário” (*DSF* de 12.07.2003, p. 17878).

Ao discursar sobre a matéria, o primeiro signatário da PEC, o então Senador Jorge Bornhausen, falou sobre a importância da analisada flexibilização do monopólio estatal sobre as referidas tecnologias de medicina nuclear. “Bornhausen enfatizou a relevância da tecnologia PET (tomografia por emissão de pósitrons) na detecção precoce de pequenas lesões tumorais, assim como de disfunções metabólicas, neurológicas e cardíacas”. “Esses radioisótopos são usados na medicina para detectar, em estágio inicial, doenças inflamatórias, metabólicas e infecciosas, câncer e problemas cardíacos” (*Jornal Senado*

Federal, 08.02.2006).

Portanto, a quebra do monopólio em análise representa um grande avanço. Trata-se de salutar abertura “sustentada”, na medida em que, como visto, a atividade continua sendo fiscalizada e controlada pela União.

■ 20.4. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conforme anota José Afonso da Silva, dois são os sistemas financeiros regulados na Constituição:

- **público**: “que envolve os problemas das finanças públicas e os orçamentos públicos, constante dos arts. 163 a 169”;

- **parapúblico**: “que ela denomina de *Sistema Financeiro Nacional*, previsto no art. 192, cujos incisos e parágrafos foram desconstitucionalizados pela Emenda Constitucional 40/2003”.

Apesar disso, continua o mestre, “... ainda se pode dizer que o Sistema Financeiro Nacional cuida das instituições financeiras creditícias, públicas ou privadas, de seguro, previdência (privada) e capitalização, todas sob estrito controle do Poder Público (art. 192). O *Banco Central*, que é instituição financeira, constitui, em verdade, um elo entre as duas ordens financeiras (arts. 164 e 192)”.⁷

O art. 192, na redação determinada pela EC n. 40/2003, assim estabeleceu: “o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por **leis complementares** que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”.

A novidade foi retirar diversas regras que constavam dos incisos do art. 192, entre elas a previsão de taxa de juros reais de 12% a.a.

Não obstante a crítica pessoal deste autor e de diversos outros, bem como de alguns tribunais (*vide Julgados do TARGS*, 81/314), o STF entendia que o

revogado § 3.º do art. 192, que fixava as taxas dos juros reais não superiores a 12% a.a., era norma constitucional de **eficácia limitada**, dependente de **lei complementar** para sua aplicação prática.

Conforme visto, a EC n. 40, de 29.05.2003 (PEC n. 53/99 da CD e n. 21/97 do SF), ao tratar do Sistema Financeiro Nacional, alterou a redação do inciso V do art. 163 e do *caput* do art. 52 do ADCT, revogando todos os incisos e parágrafos do art. 192, permitindo a sua regulamentação **por mais de uma lei complementar** e não por apenas uma lei complementar como era antes.

Em razão dessa nova sistemática, a já desprestigiada taxa de juros reais de 12% a.a. desconstitucionaliza-se, infelizmente, assim como as importantes regras que constavam do referido art. 192.

No parecer do relator à PEC n. 53, a reforma buscou “... superar as dificuldades de regulamentação do art. 192 da Constituição Federal e viabilizar a aprovação de uma nova lei estruturadora do sistema financeiro nacional”, uma vez que o STF já havia resolvido que, na vigência da antiga regra, antes da EC n. 40/2003, portanto, o sistema financeiro deveria ser regulamentado por uma única lei complementar.

Finalmente, cabe destacar a **SV 7/2008**, com o seguinte teor: “a norma do § 3.º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

■ 20.5. QUESTÕES

1. (Juiz Federal do Trabalho Substituto da 3.ª Região/2009) Assinale verdadeiro ou falso (adaptada). A Constituição afirma o direito de propriedade nos direitos e garantias fundamentais, descrevendo-o como um dos direitos e deveres individuais e coletivos e também dentro da ordem econômica e financeira, como um dos princípios gerais da atividade econômica, porém, nas duas situações, subordina seu uso ao cumprimento de uma função social.

2. (6.º Concurso Público Outorga de Delegações de Notas e de Registro/TJ SP —

2009) A ordem econômica nacional, conforme expresso preceito constitucional, deve observar, dentre outros, os princípios de:

- a) tratamento favorecido para as empresas, propriedade plena e redução do desemprego.
- b) soberania nacional, propriedade pública, propriedade privada e propriedade social.
- c) função social da propriedade, redução de desigualdades trabalhistas e pleno emprego.
- d) livre concorrência, defesa do consumidor e defesa do meio ambiente.

3. (Atividades Notariais Registro/TJ MS — Vunesp/2009) Na ordem econômica e financeira, a Constituição Federal estabelece que:

- a) as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
- b) a lei regulará o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
- c) como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para os setores público e privado.
- d) o Estado regulará a organização da atividade garimpeira, impedindo a participação de empresas estrangeiras na atividade, levando em conta a degradação do meio ambiente e a proteção econômico-social dos garimpeiros.
- e) dependerá de autorização ou concessão da União o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

4. (AFRFB/2005 — ESAF) Sobre os princípios gerais da ordem econômica e o sistema financeiro nacional, na Constituição de 1988, marque a única opção correta.

- a) É princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no Brasil.
- b) Nos termos da Constituição Federal, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado apenas é permitida quando houver relevante interesse coletivo, conforme definido em lei.
- c) As autorizações para pesquisa de recursos minerais serão concedidas sem prazo determinado, porém não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.
- d) A concessão ou permissão para a prestação de serviços públicos por empresas privadas

far-se-á sempre por meio de licitação.

- e) À redução e ao restabelecimento da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de comercialização de petróleo e seus derivados, aplica-se o princípio da anterioridade.

5. (AFRFB/2005 — ESAF) Sobre os princípios gerais da atividade econômica e sobre a assistência social, na Constituição de 1988, marque a única opção correta.

- a) Nos termos da Constituição Federal, pode a União contratar com particulares a realização de lavra e enriquecimento de minérios e minerais nucleares.
- b) A Constituição Federal veda o transporte de mercadorias na cabotagem por embarcações estrangeiras.
- c) Nos termos da Constituição Federal, havendo reciprocidade de tratamento, o atendimento de requisições de documento ou informação de natureza comercial, feitas por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, não dependerá de autorização do Poder competente.
- d) A prestação de assistência social está vinculada ao recolhimento, por parte do beneficiado, de contribuição para a seguridade social.
- e) É diretriz constitucional de organização das ações governamentais na área de assistência social a participação da população, por meio de organizações representativas, na formação das políticas.

6. (Notário SP/2008) Assinale a alternativa incorreta.

- a) A refinação de petróleo constitui monopólio da União Federal.
- b) A defesa do consumidor é um dos princípios da ordem econômica instituídos pela Constituição Federal.
- c) A livre concorrência não é um dos princípios da ordem econômica instituídos pela Constituição Federal.
- d) O Estado brasileiro pode assumir a exploração direta de atividade econômica quando necessário à segurança nacional.

7. (Analista Técnico da SUSEP — ESAF 2010) São princípios da Ordem Econômica, exceto:

- a) tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
- b) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

- c) propriedade privada.
- d) integração nacional.
- e) função social da propriedade.

8. (Magistratura — TRT/23) De acordo com a Constituição da República de 1988, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Assinale o item que NÃO corresponde a um princípio consagrado expressamente na Constituição quanto à ordem econômica:

- a) Função social da propriedade.
- b) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
- c) Livre associativismo e cooperativismo.
- d) Redução das desigualdades regionais e sociais.
- e) Busca do pleno emprego.

9. (Magistratura/TRT-24 — 2012) A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados alguns dos princípios a seguir transcritos, COM EXCEÇÃO DE APENAS UMA DAS ALTERNATIVAS:

- a) Soberania nacional.
- b) Busca do pleno emprego;
- c) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País;
- d) Defesa do consumidor;
- e) Pluralismo político.

10. (Auditor Fiscal — Prefeitura do Município de São Paulo — FCC/2012) Considerados os princípios constitucionais da ordem econômica, lei municipal que impedisse a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área do Município seria:

- a) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio da livre

concorrência.

- b) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio da soberania nacional.
- c) compatível com a Constituição da República, em virtude do princípio da função social da propriedade.
- d) compatível com a Constituição da República, em virtude do princípio da busca do pleno emprego.
- e) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.

11. (Analista Jurídico/SC — TJ — 2011) Segundo a Constituição Federal, a Ordem Econômica é fundada na valoração do trabalho humano e na livre-iniciativa observados alguns princípios, NÃO se incluindo entre estes:

- a) A livre concorrência.
- b) A função social da propriedade.
- c) A integração econômica com os povos latino-americanos.
- d) A defesa do consumidor.
- e) A redução das desigualdades regionais e sociais.

12. (ANTT — Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres — CESPE/UnB/2013) A respeito da ordem jurídico-econômica, julgue o item a seguir:

A primeira Constituição brasileira que separou a ordem econômica da ordem social foi a de 1988.

■ GABARITO ■

1. “correto”.
2. “d”. Art. 170, IV, V, VI, da CF/88.
3. “a”. Art. 173, § 2.º, da CF/88.
4. “d”. Esta questão foi ANULADA nos termos do <i>Edital ESAF n. 7, de 20.01.2006</i> . Cf. art. 177, § 1.º. A letra “a” está errada por violar a literalidade do art. 170, IX. A letra “b” está errada por

violar a literalidade do art. 173, <i>caput</i>. A letra “c” está <i>errada</i> por violar o art. 176, § 1.º. A letra “e” está errada por violar o art. 177, § 4.º, I, “b”. Pedimos vênha para informar que, normalmente, as questões estão pedindo o conhecimento da literalidade dos dispositivos. Então, como técnica de estudo, leiam a “letra da lei”!
5. “e”, de acordo com a literalidade do art. 204, II, da CF/88. A letra “a” está <i>errada</i> por violar a literalidade do art. 177, V. CUIDADO, pois, a partir da redação conferida ao referido dispositivo pela EC n. 49/2006, passou a existir <i>exceção</i> não prevista à época da prova de 2005. A letra “b” está <i>errada</i> por violar a literalidade do art. 178, parágrafo único. A letra “c” está errada por violar a literalidade do art. 181. A letra “d” está <i>errada</i> por violar a literalidade do art. 203, <i>caput</i>, que estabelece que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
6. “c”. Art. 170, IV, da CF/88.
7. “d”. Cf. art. 170, IX, VI, II e III, na ordem das alternativas.
8. “c”, nos termos do art. 170 da CF/88.
9. “e”. Confira os incisos do art. 170. O pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1.º, V, da CF/88.
10. “a”.
11. “c”. Cf. arts. 170, IV, III, V e VII (na ordem das alternativas “a”, “b”, “d” e “e”). A letra “c” não foi prevista como princípio da Ordem Econômica, mas está relacionada ao tema dos princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais (art. 4.º, parágrafo único).
12. “certo”. Cf. parte teórica.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

■ 21.1. JUSTIFICATIVAS INICIAIS

Os **princípios fundamentais** encontram-se no início da Constituição, mais precisamente no *Título I*, arts. 1.º a 4.º.

Observa-se, curiosamente, que, no presente estudo, o tema está alocado ao final.

Qual o motivo?

Pelo menos, nesse primeiro momento, entendemos que, para o livro, o tema significa o fechamento de tudo o que se falou.

Em outras palavras, poderíamos até imaginar que os princípios fundamentais seriam o roteiro de estudo de todo o Direito Constitucional.

Ao longo deste trabalho, todos os temas já foram direta ou indiretamente tratados, com exceção do art. 4.º, que define os *princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais* e que deverão ser aprofundados nos livros de *direito internacional*.

Se por um lado a palavra “princípio”, que vem do termo latino *principium*, *principii*, traz ínsita a ideia de **começo, origem, base, ponto de partida**, podemos imaginar, também, que os *princípios fundamentais* significam, do mesmo modo, o **ponto de chegada** em interessante ciclo que se fecha.

Passemos a tratar de cada um dos artigos.

■ **art. 1.º, caput:** estabelece que a *República Federativa* do Brasil,

formada pela *união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal*, constitui-se em *Estado Democrático de Direito*;

■ **art. 1.º, I a V:** define os *fundamentos* da República Federativa do Brasil;

■ **art. 1.º, parágrafo único:** trata da *democracia semidireta* ou *participativa*;

■ **art. 2.º:** estatui a *separação de “Poderes”*;

■ **art. 3.º:** trata dos *objetivos fundamentais* da República Federativa do Brasil;

■ **art. 4.º:** estatui os *princípios* que regem a República Federativa do Brasil em suas *relações internacionais*.

■ 21.2. REPÚBLICA

Conforme já referimos, em 15 de novembro de 1889, a República era proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, afastando-se do poder D. Pedro II e toda a dinastia de Bragança, sem ter havido significativa movimentação popular.

Tratava-se mais de um golpe de Estado militar e armado que de qualquer movimento do povo. A República nascia, então, sem legitimidade. Prevista no texto de 1891, permanece até hoje.

No texto de 1891 a *República* surge como cláusula pétrea e assim é mantida em todas as Constituições, exceto na de 1988 em que aparece como **princípio sensível** (art. 34, VII, “a”).

Apesar de não ser cláusula pétrea, por meio de plebiscito, o “povo” confirmou a forma republicana, não podendo, portanto, emenda à Constituição instituir a Monarquia, sob pena de se violar a **soberania popular**, a não ser que haja, necessariamente, nova consulta popular (art. 2.º do ADCT).

■ 21.3. FEDERAÇÃO

A forma de Estado adotada pelo texto de 1988 é a **Federação** e não o Estado Unitário, tema já estudado no *capítulo 7*, ao qual remetemos o ilustre leitor.

O nosso federalismo se deu por **desagregação** a partir do Estado Unitário e estabelece-se no texto de 1988 a Federação como **cláusula pétrea**, nos termos do art. 60, § 4.º, I.

A solidez do sistema está na consagração da ideia de **indissolubilidade do vínculo federativo** (*inexistência do direito de secessão*), havendo instrumentos de estabilização de eventual crise, como, no caso, a intervenção federal (art. 34, I).

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel da União Federal, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios em verdadeiro **federalismo assimétrico**, em razão da falta de homogeneidade entre os entes federativos (art. 1.º, *caput*, c/c o art. 18).

■ 21.4. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

■ 21.4.1. Aspectos gerais

A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito.

A previsão desse regime jurídico é reforçada pelo **princípio democrático** que marcou o texto de 1988 e pela cláusula contida no parágrafo único do art. 1.º, ao dispor que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Estamos diante da **democracia semidireta** ou **participativa**, um “sistema híbrido”, uma democracia representativa, com peculiaridades e atributos da democracia direta.

Pode-se falar, então, em participação popular no poder por intermédio de um processo, no caso, o exercício da soberania que se instrumentaliza por meio do **plebiscito, referendo, iniciativa popular**, bem como outras formas, como a

ação popular.

Remetemos o nosso ilustre leitor para a discussão contida no *capítulo 14*, sobre a dimensão dos direitos fundamentais e a conexão com a evolução do Estado, que deixa de ser liberal, passando para Estado Social com a perspectiva, na atualidade, de um Estado Pós-Social de direito.

■ 21.4.2. A Lei da Anistia, a ADPF 153 e a decisão da “Corte Interamericana de Direitos Humanos”

O art. 1.º da Lei n. 6.683/79 concedeu a **anistia** a **todos** quantos, no período compreendido entre 02.09.1961 e 15.08.1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.

O *Conselho Federal da OAB* interpôs a **ADPF 153**, objetivando a anulação, pela Suprema Corte, do perdão dado pela **Lei da Anistia** aos representantes do Estado (policiais e militares) acusados da prática de atos de tortura durante o regime militar.

Por **7 x 2**, o STF rejeitou o pedido de revisão, e reproduzimos parte da *ementa* do julgamento, que bem resume o entendimento em acórdão, denso, de 266 folhas:

‘EMENTA: (...). A chamada Lei da anistia veicula uma decisão política assumida naquele momento — o momento da transição conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é uma lei-medida, não uma regra para o futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no momento em que foi conquistada. 6. A Lei n. 6.683/79 precede a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes — adotada pela Assembleia Geral em 10 de dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 — e a Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de tortura; e o preceito veiculado

pelo artigo 5.º, XLIII, da Constituição — que declara insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, entre outros crimes — não alcança, por impossibilidade lógica, anistias anteriormente à sua vigência consumadas. A Constituição não afeta leis-medida que a tenham precedido. 7. No Estado democrático de direito o Poder Judiciário não está autorizado a alterar, a dar outra redação, diversa da nele contemplada, a texto normativo. Pode, a partir dele, produzir distintas normas. Mas nem mesmo o Supremo Tribunal Federal está autorizado a reescrever leis de anistia. 8. Revisão de lei de anistia, se mudanças do tempo e da sociedade a impuserem, haverá — ou não — de ser feita pelo Poder Legislativo, não pelo Poder Judiciário. 9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988; a nova Constituição a [re]instaurou em seu ato originário” (ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau, j. 29.04.2010, Plenário, *DJE* de 06.08.2010).

Posteriormente, em 14.12.2010, a *Corte Interamericana de Direitos Humanos*, no julgamento do caso *Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”)* versus *Brasil*, entendeu que o Brasil é responsável pela desaparecimento forçada de 62 pessoas, ocorrida entre os anos 1972 e 1974, na denominada região do Araguaia.

A Corte concluiu que a **Lei da Anistia**, ao impedir investigações, negar acesso a arquivos e não prever sanções às violações de direitos humanos, é **incompatível** com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil perante a *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*.

Eis o embate, a decisão da Suprema Corte brasileira, mantendo a Lei da Anistia e a condenação do Brasil perante a Corte Interamericana, declarando a referida lei incompatível com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

Não há dúvida de que, muito embora a decisão da Corte Interamericana não anule a da jurisdição nacional (STF), o Brasil vai sofrer as consequências no plano internacional, sujeitando-se às sanções previstas na Convenção.

Temos de lembrar, ainda, a **Lei n. 12.528/2011**, que criou, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a **Comissão Nacional da Verdade**, com a

finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8.º do ADCT, a fim de efetivar o **direito à memória e à verdade histórica** e **promover a reconciliação nacional**.

A Comissão Nacional da Verdade, composta de forma **pluralista**, será integrada por 7 membros, designados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos.

Por fim, de acordo com o art. 3.º da lei, são **objetivos** da *Comissão Nacional da Verdade*:

- esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no *caput* do art. 1.º;
- promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior;
- identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos mencionadas no *caput* do art. 1.º e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;
- encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art. 1.º da Lei n. 9.140/95;
- colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos;
- recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e
- promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações.

■ 21.5. SEPARAÇÃO DE “PODERES”

O art. 2.º consagra serem Poderes da União, independentes e harmônicos entre si:

■ **Legislativo;**

■ **Executivo;**

■ **Judiciário.**

Cada um dos “Poderes” é estudado em separado, respectivamente, nos capítulos 9, 10 e 11, aos quais remetemos o nosso caro leitor para as importantes discussões.

Retomando, conforme já explicitado, os “Poderes” (órgãos) são independentes entre si, cada qual atuando dentro de sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida e assegurada quando da manifestação do *poder constituinte originário*, daí ser mais adequado falarmos em **órgãos** que exercem **funções**, *típicas* (inerentes à essência) e *atípicas* (do órgão, mas sem ser a sua essência).

Dessa forma, diante do **princípio da indelegabilidade de atribuições**, nenhum Poder (órgão) poderá transferir função que lhe é típica ou expressamente prevista como atípica a outro.

Lembre-se de que a CF/88 erigiu à categoria de **cláusula pétrea a separação de Poderes**, conforme se observa pelo art. 60, § 4.º, III. 1

■ 21.6. FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O art. 1.º, I a V, enumera os **fundamentos** da República Federativa do Brasil:

■ **soberania**: do conjunto formado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Discute-se, na atualidade, a amplitude da soberania de determinado Estado, especialmente diante da ideia de um poder constituinte transnacional ou supranacional. Esse parece ser o grande desafio, qual seja, encontrarmos um equilíbrio entre a soberania do Estado

e a necessidade de adequação ao conjunto dentro da ideia de um constitucionalismo globalizado;

■ **cidadania:** materializada tanto na ideia de capacidade eleitoral ativa (ser eleitor) e passiva (ser eleito) como na previsão de instrumentos de participação do indivíduo nos negócios do Estado. Assim, o conceito de cidadania não se restringe a direitos políticos, mas nessa visão muito mais abrangente e que engloba, também, os direitos e deveres fundamentais;

■ **dignidade da pessoa humana:** regra matriz dos direitos fundamentais, tema aprofundado no *capítulo 14* deste estudo e que pode ser bem definido como o núcleo essencial do constitucionalismo moderno. Assim, diante de colisões, a dignidade servirá para orientar as necessárias soluções de conflitos;

■ **valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa:** nos termos do art. 170, *caput*, da CF/88, a *ordem econômica*, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, funda-se em dois grandes pilares, quais sejam, a *valorização do trabalho humano* e a *livre-iniciativa*. Dessa maneira, o constituinte, além de privilegiar o modelo capitalista, estabelece, como finalidade da ordem econômica, assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, afastando-se, assim, de um Estado absenteísta nos moldes do liberalismo;

■ **pluralismo político:** a partir dessa ideia, enaltece-se uma sociedade plural, em que se consagra o respeito à pessoa humana e sua liberdade.

■ 21.7. OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Os objetivos fundamentais estão previstos no art. 3.º da CF/88. Uma vez estruturada a República Federativa do Brasil, ela terá metas a serem atingidas, orientadoras das políticas governamentais, destacando-se:

■ **construir uma sociedade livre, justa e solidária:** a solidariedade aparece aqui como consagração dos direitos de 3.ª *dimensão*, tendo sido fundamento para algumas importantes decisões como a que autorizou a

pesquisa de células-tronco embrionárias (ADI 3.510);

■ **garantir o desenvolvimento nacional:** é dever do Estado o desenvolvimento nacional, e esse objetivo vem justificando os diversos programas governamentais;

■ **erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais:** como desdobramento dessa ideia, podemos lembrar o *fundo de combate e erradicação da pobreza*, prorrogado por prazo indeterminado nos termos da EC n. 67/2010;

■ **promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação:** sem dúvida esse foi um importante argumento para o STF reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo.

■ 21.8. PRINCÍPIOS QUE REGEM A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

■ 21.8.1. Art. 4.º, CF/88

O art. 4.º da CF/88 dispõe que a República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- independência nacional;
- prevalência dos direitos humanos;
- autodeterminação dos povos;
- não intervenção;
- igualdade entre os Estados;
- defesa da paz;
- solução pacífica dos conflitos;
- repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

■ concessão de asilo político.

A discussão sobre o **asilo político** já foi apresentada no *capítulo 16, sobre nacionalidade*, ao qual remetemos o nosso ilustre leitor.

Sugerimos o aprofundamento da matéria nos livros de *direito internacional*.

Por enquanto, limitemos a nossa análise a alguns apontamentos em relação ao **Mercosul**.

■ 21.8.2. MERCOSUL

O parágrafo único do art. 4.º estabelece que a República Federativa do Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural** dos povos da **América Latina**, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Seguindo a tendência mundial (*vide* Mercado Comum Europeu, Nafta...) o Brasil, focado na implementação de um processo de regionalização, oficializou a criação do Mercado Comum do Sul (**Mercosul**), por meio da assinatura do **Tratado de Assunção**, em 1991, do qual participaram, inicialmente, **Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai** (Estados-partes),² objetivando a formação de um mercado comum, ainda não criado.

A **Venezuela** figurou como *Estado-parte em processo de adesão* e se tornaria membro pleno uma vez aprovado o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, assinado em Caracas, em 04.07.2006, pelos Presidentes dos Estados-partes do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e a Venezuela.

Nos termos do art. 49, I, o Congresso Nacional aprovou, em **16.12.2009**, o texto do referido protocolo — **DLG n. 934/2009**. A votação foi bastante apertada (35 x 27) e havia muita resistência, especialmente diante de algumas posturas, denominadas pelos parlamentares **antidemocráticas**, de Hugo Chávez.

Mesmo diante da aprovação da entrada da Venezuela pelo Brasil, bem como

pela Argentina e pelo Uruguai que já haviam deliberado, ainda faltava a manifestação do Congresso Nacional do Paraguai, havendo, inclusive, muita resistência por parte da população local.

Em 2012, tendo em vista a deposição de seu ex-presidente, o Paraguai ficou suspenso, temporariamente, do MERCOSUL, até que as eleições democráticas se efetivassem. Dessa forma, não havendo mais o embargo que era colocado pelo Paraguai, no mesmo ano, a Venezuela foi finalmente incorporada.

O **Decreto n. 7.859/2012** promulgou o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL, firmado pelos Presidentes dos Estados-Partes do MERCOSUL e da República Bolivariana da Venezuela em Caracas, em 04.07.2006.

Assim, atualmente, os Estados-partes do MERCOSUL são **Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela**. A **Bolívia** está em processo de adesão.^{[3](#)}

O mercado comum, conforme visto, será a etapa final do processo, que se encontra em andamento.

Como ensina Celso Bastos, “a primeira etapa de qualquer processo integracionista é a zona de livre comércio, que no caso do Mercosul já foi concluída. Funcionando o livre comércio, passa-se para a união aduaneira, que é a adoção de uma Tarifa Externa Comum (TEC); o Mercosul já adotou a TEC. Consolidada a união aduaneira e eliminando-se qualquer restrição relativa a bens e serviços, estar-se-á no mercado comum. O Mercosul pretende chegar até aqui. Mas o processo vai mais longe, incluindo a união econômica e a união monetária, que já estão sendo alcançadas pela União Europeia... ainda não há propriamente um mercado comum para que possa fazer jus ao seu nome: Mercado Comum do Sul”.^{[4](#)}

Importante frisar a diferença entre *Zona de Livre Comércio*, *União Aduaneira* e *Mercado Comum*, propriamente dito:

■ **Zona de Livre Comércio:** etapa ou tipo de integração em que são **eliminadas** todas as **barreiras ao comércio** entre os membros do grupo;

■ **União Aduaneira:** etapa ou tipo de integração em que, além do livre comércio entre os membros do grupo, existe a aplicação de uma **Tarifa Externa Comum** ao comércio com terceiros países (TEC — “tarifa comum cobrada por um grupo de países sócios que exigem o mesmo imposto à entrada de mercadorias provenientes de terceiros países”);

■ **Mercado Comum:** além da TEC e do livre comércio de bens, existe a **livre circulação de fatores de produção** (capital e trabalho).

“Dessa forma, os Estados-Partes iniciaram nova etapa — de consolidação e aprofundamento — em que a zona de livre comércio e a união aduaneira constituem passos intermediários para alcançar um mercado único que gere um maior crescimento de suas economias, aproveitando o efeito multiplicador da especialização, das economias de escala e do maior poder de negociação do bloco”.⁵

Em suma, o **Tratado de Assunção** (26.03.1991), ato fundacional do Mercosul, o **Protocolo de Brasília**, de 1991, e o **Protocolo de Ouro Preto**, de 1994, constituem os principais **instrumentos jurídicos do processo de integração**.

Da assinatura do Tratado de Assunção até a assinatura do Tratado de Ouro Preto (dezembro de 1994), tivemos aquilo que a doutrina denominou “**período de transição**” do processo de implantação do Mercosul.

O Protocolo de Ouro Preto, por seu turno, definiu a estrutura institucional do Mercado Comum, reconhecendo “... a personalidade jurídica de direito internacional do bloco, atribuindo-lhe, assim, competência para negociar, em nome próprio, acordos com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais. Hoje, a compatibilidade jurídica do Mercosul com a Aladi e com o Gatt, o êxito comercial da integração e o fato de ser uma entidade dotada de personalidade jurídica garantem a sua condição de parceiro econômico relevante no plano internacional”.

Em busca da **consolidação da União Aduaneira em curso**, o bloco, como meta final do processo integrativo, orienta-se para a implementação do **Mercado Comum do Sul**, marcado, fundamentalmente, pela **livre circulação de fatores**

de produção, quais sejam, o capital e o trabalho.⁶

■ 21.8.3. MERCOSUL — evolução do Sistema de Solução de Controvérsias. Tribunal Permanente de Revisão (TPR)

O sistema de solução de controvérsias no MERCOSUL surgiu com o seu nascimento, qual seja, com a assinatura do **Tratado de Assunção** (1991), cujo Anexo III estabeleceu um **sistema provisório**, fundado em negociações diretas entre os Estados-Partes e que vigoraria até 31.12.1994, quando passaria a ser adotado um *Sistema Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum*.

No caso de não lograrem uma solução, estabelecia referido anexo que os Estados submeteriam a controvérsia à consideração do **Grupo Mercado Comum**, que, após avaliar a situação, formularia, no lapso de 60 dias, as recomendações pertinentes às Partes.

Se no âmbito do Grupo Mercado Comum tampouco fosse alcançada a solução, a controvérsia seria elevada ao **Conselho do Mercado Comum** para que este adotasse as recomendações pertinentes.

Em seguida, no mesmo ano, em complemento ao Tratado de Assunção, firmou-se o **Protocolo de Brasília**, que **manteve o sistema provisório de solução de controvérsias**, até que entrasse em vigor o *Sistema Permanente* a que se refere o número 3 do Anexo III do Tratado de Assunção.

Finalmente, em 18.02.2002, foi assinado o **Protocolo de Olivos**, aperfeiçoando o sistema de solução de controvérsias vigente e criando, então, o **Tribunal Permanente de Revisão (TPR)**, considerando “a necessidade de garantir a correta interpretação, aplicação e cumprimento dos instrumentos fundamentais do processo de integração e do conjunto normativo do MERCOSUL, de forma consistente e sistemática”.⁷

O TPR, de acordo com as regras estabelecidas, poderá se reunir como primeira e única instância ou como tribunal recursal (arts. 17, 19 e 23 do *Protocolo de Olivos — PO*), bem como emitindo opiniões consultivas (art. 3.º

do PO).

As **opiniões consultivas** “são pronunciamentos fundados — **não vinculantes nem mesmo obrigatórios** — do TPR com relação a perguntas de caráter jurídico com respeito à interpretação e aplicação das normas MERCOSUL em um **caso concreto** com o objetivo de resguardar sua aplicação uniforme no território dos Estados-Partes (arts. 3 e 11 Dec. CMC n. 37/2003, *Regulamento do Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias* — RPO). Destes pronunciamentos podem recorrer os Estados-Partes, os órgãos decisórios do MERCOSUL (CMC, GMC e CCM), os **Superiores Tribunais de Justiça dos Estados-Partes** e o Parlamento do MERCOSUL (arts. 2, 3 e 4 RPO, Dec. CMC n. 2/2007 e art. 13 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL)”.⁸

No caso de solicitação pelos Tribunais Superiores dos Estados-Partes com jurisdição nacional, reforça o art. 4.º, RPO, que as opiniões consultivas devem dizer respeito exclusivamente à interpretação jurídica das normas do MERCOSUL mencionadas no art. 3.º, § 1.º, desde que estejam ligadas a causas que estão em curso perante o Judiciário do Estado-Parte. O procedimento para a concretização das opiniões consultivas será regulado pelos Tribunais Superiores dos Estados-Partes.

Pois bem, nesse sentido, de maneira bastante interessante, o **STF** (no caso o “Tribunal Superior”) **regulamentou o procedimento nos termos da Emenda Regimental n. 48/2012**, que introduziu o art. 7.º, VIII, bem como os arts. 354-H a 354-M ao *RISTF*.

Trata-se de **procedimento administrativo**, e não jurisdicional, e que poderá ser instaurado pelo juiz da causa ou alguma das partes,⁹ deixando clara a regra regimental que a opinião consultiva emitida pelo TPR **não terá caráter vinculante nem obrigatório**.

■ 21.9. QUESTÕES

1. (MP/78.º/SP) Ao consagrar o pluralismo político, a Constituição do Brasil institui:

- a) um dos fundamentos da República;
- b) os sindicatos como representantes das categorias sociais da produção;
- c) a multiplicidade de legendas partidárias;
- d) o princípio da cooperação entre os povos;
- e) o princípio democrático.

2. (OAB/114.º/SP) São objetivos fundamentais:

- a) a garantia do desenvolvimento nacional, a prevalência dos direitos humanos e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária;
- b) a prevalência dos direitos humanos, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais;
- c) a garantia do desenvolvimento nacional, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a erradicação da pobreza;
- d) a prevalência dos direitos humanos, a redução das desigualdades regionais e a garantia do desenvolvimento nacional.

3. (Acadepol 2007-MG) No Brasil, a Constituição estabelece como princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito:

- a) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa e o pluralismo político.
- b) A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos e a igualdade entre os Estados.
- c) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais.
- d) A defesa da paz, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a solução pacífica dos conflitos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo.

4. (TJ/AM 2005 — ISAE/FGV) Assinale a alternativa que apresente corretamente os fundamentos da República Federativa do Brasil:

- a) soberania, cidadania, direito de resposta, acesso à informação e valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa;
- b) soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa e pluralismo político;
- c) soberania, cidadania, prevalência dos direitos humanos, acesso à informação e

pluralismo político;

d) soberania, cidadania, bem-estar social, valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa e pluralismo político;

e) soberania, cidadania, autonomia, independência e dignidade da pessoa humana.

5. (Defensoria Pública de São Paulo — 2006/FCC) Em relação à dignidade da pessoa humana, prevista pela Constituição Federal de 1988 como fundamento da República Federativa do Brasil, é possível afirmar:

a) É um direito público subjetivo expresso numa norma-regra.

b) Por ser fundamento e princípio constitucional estruturante é densificada ao longo do texto constitucional.

c) Por ser uma norma programática a sua efetivação dependerá de políticas públicas que venham a ser adotadas pelos governantes.

d) É suficiente para sua realização o respeito aos direitos individuais clássicos: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

e) Exprime um conceito extremamente vago que comporta ampla discricionariedade judicial, devendo, portanto, ser evitado em demandas judiciais.

6. (Defensoria Pública de São Paulo — 2006/FCC) O reconhecimento de iguais direitos aos homossexuais e a igual valoração jurídica das relações afetivas e eróticas entre pessoas do mesmo sexo:

a) dependem de modificação constitucional através de manifestação do Poder Constituinte Derivado, uma vez que o inciso IV do artigo 3.º não previu a discriminação por orientação sexual.

b) ferem o princípio democrático e a regra da maioria, já que o Direito, ao determinar ou escolher uma moral, deve privilegiar a moral da maioria.

c) decorrem do sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais, que proíbe quaisquer formas de discriminação e garante a dignidade da pessoa humana.

d) estão sujeitos à evolução social e cultural da sociedade em que vivemos, uma vez que para o “homem comum” as práticas homossexuais são antinaturais e contrariam as convicções religiosas compartilhadas.

e) necessitam de legislação infraconstitucional para efetivação, pois as normas constitucionais incidentes são de eficácia limitada.

7. (ESAF — PFN/2007) A República Federativa do Brasil, formada pela união

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos o que se encontra na única formulação correta, entre as opções abaixo:

- a) A independência nacional; a soberania; a sociedade livre, organizada e solidária; a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual.
- b) A cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e econômicos da livre-iniciativa; o pluralismo político.
- c) A soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e a livre concorrência; o pluralismo político e a defesa da paz.
- d) A soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa; o pluralismo político.
- e) A cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores econômicos e sociais do trabalho, da livre-iniciativa e da livre concorrência; o pluralismo político.

8. (MP-SP — 84.º concurso) Não constitui fundamento da República Federativa do Brasil:

- a) a soberania.
- b) a cidadania.
- c) a dignidade da pessoa humana.
- d) os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa.
- e) a liberdade de expressão.

9. (MP-SP — 84.º concurso) Não é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, como expressamente previsto na Constituição:

- a) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- b) erradicar o analfabetismo e a fome.
- c) garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza.
- d) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- e) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

10. (Analista Administrativo MPU — CESPE/UnB 2010) A respeito dos princípios fundamentais, da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos sociais, julgue o item a seguir.

A dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apresenta-se como direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos e como dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.

11. (50.º concurso MP/MG — 2010) Entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, NÃO se pode incluir:

- a) a soberania.
- b) o pluralismo político.
- c) o trabalho e a livre-iniciativa.
- d) a cidadania.

12. (Técnico Judiciário Auxiliar — TJ-SC — Secretaria/2011) Nos termos da Constituição Federal, o Brasil em suas relações internacionais deve buscar integrar-se com os países da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Entre as formas de integração previstas, NÃO se inclui:

- a) a econômica;
- b) a política;
- c) a social;
- d) a militar;
- e) a cultural.

13. (Perito Papiloscópico — PC-ES — CESPE/UnB/2011) Julgue o próximo item, a respeito dos princípios constitucionais:

O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental e absoluto.

14. (Delegado de Polícia — PC-MG/2011) São fundamentos essenciais da República Federativa do Brasil:

- a) independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, integração econômica e cultural.
- b) concessão de asilo político, repúdio ao terrorismo e ao racismo, eleições diretas, não intervenção do Estado.
- c) soberania nacional, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre-iniciativa, pluralismo político.

- d) liberdade de exercício de qualquer ofício ou profissão, inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, liberdade de associação para fins lícitos, direito de propriedade, desde que atendidas suas funções sociais.

15. (Promotor de Justiça/SP — 2011) Examine os tópicos seguintes. No regime constitucional brasileiro, os itens elencados são, respectivamente:

- I. o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça;
- II. a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa; o pluralismo político;
- III. construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
- IV. independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; concessão de asilo político.
- a) objetivos do Estado Democrático, do preâmbulo da Constituição Federal; objetivos fundamentais da república; fundamentos da República Federativa do Brasil; princípios das relações internacionais.
- b) fundamentos da República Federativa do Brasil; objetivos fundamentais da república; agenda político-partidária estranha à Constituição; princípios das relações internacionais.
- c) objetivos fundamentais da república; princípios das relações internacionais; objetivos do Estado Democrático, do preâmbulo da Constituição Federal; fundamentos da República Federativa do Brasil.
- d) objetivos do Estado Democrático, do preâmbulo da Constituição Federal; fundamentos da República Federativa do Brasil; objetivos fundamentais da república; princípios das relações internacionais.
- e) agenda político-partidária estranha à Constituição; princípios das relações internacionais; objetivos fundamentais da república; fundamentos da República Federativa do Brasil.

16. (Procurador do Trabalho — 2008) Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) de acordo com o Protocolo de Ouro Preto o MERCOSUL não poderá, no uso de suas atribuições, praticar atos necessários à realização de seus objetivos, em especial contratar, adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, comparecer em juízo, conservar fundos e fazer transferências;
- b) o Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares, as decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL, adotadas desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção, os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos são fontes jurídicas do MERCOSUL;
- c) a personalidade jurídica do MERCOSUL, de acordo com o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção — Protocolo de Ouro Preto — é de direito internacional;
- d) o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) foi criado pelo Tratado de Assunção de 26 de março de 1991, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas encontra-se aberto à adesão de outros países;
- e) não respondida.

17. (Procurador do Trabalho — 2006) Assinale a alternativa INCORRETA: Em relação ao MERCOSUL, é INCORRETO afirmar que:

- a) o tratado de constituição do Mercado Comum do Sul foi firmado em 1991 pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas encontra-se aberto à adesão de outros países;
- b) o MERCOSUL pretende a uniformização dos sistemas jurídicos dos Estados-Membros no que tange às relações de trabalho e à seguridade social;
- c) o MERCOSUL tem finalidade preponderantemente econômica;
- d) no MERCOSUL, vigora o sistema arbitral de solução de controvérsias;
- e) não respondida.

18. (Oficial de Controle Externo — TCE-RS) À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte, a respeito dos princípios fundamentais:

A independência nacional, a defesa da paz e a concessão de asilo político são princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil.

19. (Administrador/MS — CESPE/UnB/2013) Considerando as disposições constitucionais a respeito dos princípios fundamentais, julgue o item a seguir:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 73/2013, são considerados Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas.

20. (Policial Rodoviário Federal — CESPE/UnB/2013) No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir:

Decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes a impossibilidade de que um poder exerça função típica de outro, não podendo, por exemplo, o Poder Judiciário exercer a função administrativa.

21. (Técnico Judiciário — TRF3 — FCC/2014) A dignidade da pessoa humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 1988, deve ser entendida como:

- a) uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade reconhecida pela Constituição.
- b) um direito individual garantido somente aos brasileiros natos.
- c) uma decorrência do princípio constitucional da soberania do Estado Brasileiro.
- d) um direito social decorrente de convenção internacional ratificada pelo Estado Brasileiro.
- e) um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil.

■ GABARITO ■

1. “a”. Conforme o art. 1.º, V, da CF/88.
2. “c”. Cf. art. 3.º, I, II, III, da CF. As alternativas “a”, “b” e “d” estão erradas apenas pela prevalência dos direitos humanos, que é princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais (art. 4.º, II).
3. “a”. Art. 1.º, I a V, da CF/88.
4. “b”. Art. 1.º, I a V, da CF/88.
5. “b”.

6. “c”.
7. “d”.
8. “e”.
9. “b”.
10. “certo”.
11. “c”. Cf. art. 170, <i>caput</i> .
12. “d”, nos termos do parágrafo único do art. 4.º da CF/88.
13. “errado”.
14. “c”, nos termos do art. 1.º da CF/88.
15. “d”, nos termos da literalidade do preâmbulo e dos arts. 1.º, 2.º e 4.º da CF/88.
16. “a”.
17. “b”.
18. “certo”, de acordo com o art. 4.º, I, VI, X, da CF/88.
19. “errado”. Cf. art. 2.º, da CF/88.
20. “errado”. Conforme anunciado neste capítulo e desenvolvido no <i>capítulo 8</i> , devemos reconhecer as funções típicas e atípicas.
21. “e”.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OUTROS TEMAS

■ 22.1. EXPLICAÇÃO DA PROPOSTA

Nosso prestigiado leitor deve estar se questionando sobre o motivo de estarmos abrindo um novo capítulo, até fora da lógica didática da disposição do livro.

A estratégia se justifica pelo fato de que alguns temas (assuntos) não estão atrelados aos pontos específicos do direito constitucional.

Assim, com o objetivo de destacar as atualidades legislativas, jurisprudenciais ou legais, resolvemos abrir este novo tópico.

A partir da 16.^a edição, escrevemos algumas linhas, poucas, sobre os **princípios constitucionais da administração pública**, até porque, em razão da *complexidade dos concursos*, a leitura de livros específicos da matéria de *direito administrativo* se mostra **indispensável**.

■ 22.2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os **princípios constitucionais da administração pública** estão explicitados no art. 37, *caput*, que sofreu importante modificação com a **EC n. 19/98**, como se observa no quadro abaixo:

ART. 37, CAPUT REDAÇÃO ORIGINAL	ART. 37, CAPUT REDAÇÃO DADA PELA EC N. 19/98
■ A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de <i>legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade</i>	■ A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de <i>legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência</i>

A doutrina identifica outros agregados aos explícitos do art. 37, *caput*, de igual importância, mas que serão aprofundados nos livros de *direito administrativo*, já tendo alguns sido tratados neste estudo, a saber:

- princípio da supremacia do interesse público sobre o privado;
- princípio da finalidade;
- princípio da razoabilidade;
- princípio da proporcionalidade;
- princípio da responsabilidade do Estado: art. 37, § 6.º.

■ 22.2.1. Princípio da legalidade

Conforme já escrevemos em *direitos fundamentais*, o **princípio da legalidade** surgiu com o **Estado de Direito**, opondo-se a toda e qualquer forma de poder autoritário, antidemocrático.

Previsto no art. 4.º da *Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão*, está contemplado, além da indicação expressa no art. 37, *caput*, nos arts. 5.º, II, e 84, IV, da CF/88:

- **art. 5.º, II: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.**

Mencionado princípio deve ser lido de forma diferente para o **particular** e para a **Administração**.

O **particular** pode fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da **autonomia da vontade**, lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com o da **dignidade da pessoa humana** e, assim, a aplicação **horizontal** dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, consoante estudado.

Por sua vez, a **Administração** só poderá fazer o que a lei permitir. Deve andar nos “trilhos da lei”, corroborando a máxima do direito inglês: *rule of law, not of men*. Trata-se do **princípio da legalidade estrita**, que, por seu turno, **não é absoluto, na medida em que a doutrina identifica** algumas restrições (já analisadas por nós neste trabalho), destacando-se:

- **medidas provisórias;**

- **estado de defesa;**

- **estado de sítio.**

A Administração deve atuar segundo a lei e nunca contra ou além da lei. Por esse motivo, os atos ilegais poderão ser invalidados de ofício, em verdadeiro exercício de **autotutela administrativa**, ou pelo Judiciário.

Confinar a atuação governamental aos parâmetros da lei, editada pelos representantes do povo, é trazer segurança e estabilidade, evitando, ainda, qualquer tipo de favoritismo por parte do administrador.

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, “o princípio da legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania popular, de exaltação da cidadania”.¹

■ **Art. 84, IV: Compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.**

O fato de ser prevista a expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução da lei confirma a **subsunção** da Administração à lei e, assim, o entendimento de que a atividade administrativa é atividade **infralegal**.

■ 22.2.2. Princípio da impessoalidade

Em interessante constatação, se todos são iguais perante a lei (art. 5.º, *caput*), necessariamente o serão perante a Administração, que deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando a todos de modo igual ou, quando necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar à igualdade real ou material.

Assim, a Administração deve sempre buscar a concretização do **interesse público** e não do particular, sentido em que a regra do **concurso público** ganha especial destaque.

Nos termos do art. 37, II, da CF/88, a investidura em **cargo** ou **emprego público** depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas** as nomeações para cargo em **comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

De maneira bastante completa, Hely Lopes Meirelles define o concurso público como “... o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se **moralidade, eficiência** e **aperfeiçoamento** do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar **igual oportunidade** a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso **afastam-se**, pois, os **ineptos** e os **apaniguados** que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos”.²

Por sua vez, Marçal Justen Filho, em importante observação, diz que “o concurso público objetiva assegurar que a seleção dos titulares de cargo de provimento efetivo oriente-se pelo **princípio da impessoalidade**. A escolha refletirá as virtudes e capacidades individuais reveladas na avaliação objetiva, segundo critérios predeterminados de virtuosidade física e (ou) capacidade intelectual”.³

Nesse sentido, conforme estabeleceu o STF, “é **nula** a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público — além das hipóteses excepcionadas pela própria Constituição —, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, **ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado** e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao **levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS**” (*tema 308 da repercussão geral/STF — RE 705.140/RS*, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014, *DJE* de 05.11.2014).

Avançando em razão da regra do concurso público, os *provimentos derivados* foram praticamente banidos do nosso ordenamento jurídico, sendo, como visto, enfaticamente afastados pela jurisprudência do STF.

Nessa linha, conforme noticiado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a antiga *Consultoria Geral da República* “... adotou o entendimento de que ‘com a promulgação da Constituição de 1988, foi banida do ordenamento jurídico brasileiro, como forma de investidura em cargo público, a ascensão funcional’. No corpo do parecer, da lavra do Consultor José Márcio Monsão Mollo, está dito que ‘estão abolidas as formas de investidura que representam ingresso em carreira diferente daquela para a qual o servidor ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, inerentes ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que acontece com a promoção, sem a qual não há carreira, mas, sim, sucessão de cargos ascendentes’ (Parecer n. CS-56, de 16.9.92, aprovado pelo Consultor Geral da República, conforme publicação no *DOU* de 24.09.92, p. 13.386-89)”.⁴

Toda essa nova orientação da jurisprudência do STF e da doutrina decorre da mudança de previsão constitucional sobre o instituto do **concurso público**, em especial a S. 685/STF, convertida na **SV 43** (j. 08.04.2015):

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Como consequência da regra do concurso, podemos citar o julgamento do

MS 28.279, no qual o STF declarou não haver “... direito adquirido do substituto, que preencheu os requisitos do art. 208 da Constituição pretérita, à investidura na titularidade de cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da CF/88, a qual exige expressamente, no seu art. 236, § 3.º, **5** a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro” (*Inf. 613/STF*, j. 16.12.2010).**6**

Ainda, dentro da ideia de **impressoalidade** destaca-se a regra dos **precatórios** (art. 100), com as suas exceções justificadas pelo princípio da isonomia substancial (cf. *item 11.12*), bem como, também com as suas exceções legais autorizadas pela Constituição, a exigibilidade de **licitação**,**7** nos termos dos arts. 37, XXI, e 175.

Finalmente, confirmando a **impressoalidade**, o art. 37, § 1.º, estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos**.

■ **22.2.2.1. A questão específica das vagas previstas em edital e o direito subjetivo à nomeação: princípio da confiança**

Como todos sabem, as regras do concurso público devem estar minuciosamente descritas no **Edital do Concurso**, que passa a ser documento essencial para se atingir os ditames constitucionais, devendo a banca estar atrelada aos seus vetores.

Isso posto, surge a pergunta: **o candidato aprovado em concurso público tem direito a nomeação?**

O STF, em julgamento extremamente importante (**RE 598.099**), em 10.08.2011, decidiu que, **se a aprovação for dentro do número de vagas previsto no Edital e dentro do prazo de validade do concurso**, o candidato terá, sim, o **direito à nomeação**.

Em suas palavras, o Min. Marco Aurélio bem define essa importante vitória

dos **Concurseiros do Brasil**: “... o Estado não pode brincar com o cidadão. O concurso público não é o responsável pelas mazelas do Brasil, ao contrário, busca-se com o concurso público a lisura, o afastamento do apadrinhamento, do benefício, considerado o engajamento deste ou daquele cidadão e o enfoque igualitário, dando-se as mesmas condições àqueles que se disponham a disputar um cargo”. “Feito o concurso, **a administração pública não pode cruzar os braços e tripudiar o cidadão**” (*Notícias STF*, 10.08.2011).

Ao publicar um Edital de Concurso, a Administração provoca, dentre outras coisas, certa mudança na vida do cidadão que confia na Administração e se predispõe a conseguir a tão sonhada vaga.

O impacto é **brutal**. Muitos alteram o curso de suas vidas em busca desse grande sonho. As **renúncias** são **inevitáveis**. O **isolamento**, necessário e inerente à tomada de decisão, é muitas vezes **penitencial**. Isso tudo leva as pessoas a testarem os seus limites.

E, como se disse, o estopim dessa mudança de comportamento é a expectativa decorrente da abertura do concurso com a fixação do número das tão sonhadas vagas a serem preenchidas.

A Administração não pode “brincar” com a vida das pessoas. Se o candidato tem os seus deveres, e olha que são muitos, como horário, regras durante a prova e tantos outros, a Administração também deve estar atrelada aos termos do Edital.

Qualquer outro entendimento, sem dúvida, caracterizaria afronta à segurança jurídica, acarretando, por consequência, ultraje ao **princípio da confiança** (*Treue und Glaube*), destacando-se aqui um **componente de ética jurídica** aplicado às **relações de direito público** como já vinha sendo sustentado pelo STF (cf. **MS 22.357**, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Dessa forma, podemos dizer que deverá haver uma **inversão do ônus da prova** para eventual não contratação por parte da Administração. Ou seja, por regra, a Administração tem o **dever** de contratar nos termos do Edital e dentro do número de vagas nele previsto.

Diante de **situações excepcionalíssimas**, e apenas nessas circunstâncias,

poderá, **de maneira motivada** (e, assim, passível de controle jurisdicional), deixar a Administração de honrar a expectativa criada.

Para o Min. Gilmar Mendes, essa excepcionalidade deve ser marcada por indispensáveis características, tais como: **superveniência**, **imprevisibilidade**, **gravidade** e **necessidade**.

Enfim, fica o **alerta**: o *princípio do concurso público* tem **força normativa** e surge no texto de 1988 como destacada **conquista da cidadania**.

Não poderá, portanto, ser desvirtuado, especialmente agora, diante da importante decisão que reconhece o **direito subjetivo à nomeação**.

Então, em situações concretas e muito particulares, parece-nos possível vislumbrar eventual incompatibilidade entre o **cadastro (desarrazoado) de reserva** e a necessária observância ao **princípio do concurso público**, pois, se em tese não há vagas a serem preenchidas no momento da abertura do Edital, conclusão essa decorrente da decisão de a Administração abrir o concurso **apenas** para o *cadastrado de reserva*, caracterizado estará o **nefasto desvio de finalidade**.

Isso sem contar algumas situações em que concursos exclusivamente para o *cadastro de reserva* são feitos com propósitos meramente arrecadatórios (em total afronta à **moralidade administrativa**) ou diante de quadro de flagrante e brutal necessidade de preenchimento de vagas e contratação.

É algo que precisamos pensar melhor e rogamos que o **cadastro de reserva** não se transforme na regra dos certames.

Nessa linha, podemos lembrar a **PEC n. 483/2010**, que, alterando o art. 37, II, **veda** a realização de concurso público exclusivamente para a formação de *cadastro de reserva*.

Pois bem, apesar de o art. 12 do Decreto n. 6.944/2009 estabelecer a **excepcionalidade** do **cadastro de reserva**, a rotina dos “concurseiros” já é muito penosa para que, diante de tantas dificuldades, essa prática se torne mais um fator a agravar o desgastante sentimento de insegurança e incertezas.

■ 22.2.2.2. **IBGE: contratação temporária, sem concurso, para demandas sazonais de pesquisa**

O **art. 37, IX, da CF/88** prescreve que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**.

Esse dispositivo foi regulamentado pela **Lei n. 8.745/93**, cujo art. 2.º, III, considerou *necessidade temporária de excepcional interesse público* a realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O STF, atentando para a situação concreta e a natureza das pesquisas sazonais, considerou **constitucional** o aludido dispositivo:

“EMENTA: É de natureza permanente a atividade de estatística e pesquisa desenvolvida pelo IBGE; sua intensidade e o volume dessas pesquisas não são os mesmos todo o tempo. Possibilidade de contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, para **atender à necessidade temporária de pessoal necessário à realização de trabalhos em determinados períodos**. Observância dos **princípios da eficiência** e da **moralidade**” (ADI 3.386, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.04.2011, Plenário, DJE de 24.08.2011).

■ 22.2.2.3. **Contratação pela administração pública, de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público (EC n. 51/2006)**

Conforme vimos, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em **concurso público** de provas ou de provas e títulos, de acordo com a **natureza** e a **complexidade** do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II).

Como segunda exceção ao princípio do concurso público (além das hipóteses de **cargo em comissão**, com a observância da particularidade do inciso V em

relação às atribuições de direção, chefia e assessoramento), destacamos as que, nos termos do inciso IX do referido art. 37, estabelecerem a possibilidade de **contratação temporária**.

A contratação temporária deverá observar os seguintes requisitos mínimos: **a)** previsão, por lei, de casos específicos de contratação; **b)** contratação necessária por prazo determinado; **c)** necessidade temporária de excepcional interesse público e, no âmbito federal, as regras mínimas e gerais da Lei n. 8.745/93, alterada pelas Leis ns. 9.849/99, 10.667/2003, 10.973/2004, 11.123/2005 e 11.204/2005.

A **EC n. 51/2006** traz outra importante hipótese de dispensa da regra geral do concurso público, estabelecendo uma nova forma de contratação pela Administração Pública.

Nos termos do art. 198, § 4.º, os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir **agentes comunitários de saúde** e **agentes de combate às endemias** por meio de **processo seletivo público**, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, lembrando as novidades introduzidas pela **EC n. 63/2010**, que abriu caminho para o piso salarial nacional e planos de carreira (cf. *item 21.6*).

Finalmente, além das hipóteses previstas no § 1.º do art. 41 e no § 4.º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de **descumprimento dos requisitos específicos**, fixados em lei, para o seu exercício.

E como ficam as contratações efetivadas anteriormente à promulgação da EC n. 51/2006, bem como as que vierem a ser efetivadas após a sua promulgação?

A teor do parágrafo único do art. 2.º da EC n. 51/2006, os profissionais que, na data da promulgação dessa Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às

endemias, na forma da lei, **ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4.º do art. 198 da Constituição Federal**, desde que tenham sido contratados a partir de anterior **processo de seleção pública** efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da Federação.

Por outro lado, após a promulgação da EC n. 51/2006, novos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4.º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

■ 22.2.3. Princípio da moralidade administrativa

A Administração Pública, de acordo com o **princípio da moralidade administrativa**, deve agir com **boa-fé, sinceridade, probidade, lhanza, lealdade e ética**.

Importante notar que o controle da *moralidade* não se confunde com o *mérito administrativo* e, por isso, pode ser **fundamento autônomo** para invalidação de ato administrativo, por meio inclusive da **ação popular**:

Art. 5.º, LXXIII — “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a **anular ato lesivo** ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Assim, não temos dúvida em afirmar que a **moralidade** tem **conteúdo jurídico**.

■ 22.2.4. Princípio da publicidade

O **princípio da publicidade** é insito ao Estado Democrático de Direito e está intimamente ligado à perspectiva de **transparência**, dever da Administração Pública, direito da sociedade.

Completando o princípio da publicidade, o art. 5.º, XXXIII, garante a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, matéria essa regulamentada pela **Lei n. 12.527/2011**.

Finalmente, os remédios do *habeas data* e mandado de segurança cumprem importante papel enquanto garantias de concretização da transparência.

■ 22.2.5. Princípio da eficiência

Se, na iniciativa privada, buscam-se a excelência e a efetividade, na Administração, outro não poderia ser o caminho, enaltecido pela EC n. 19/98, que, em boa hora, fixou a eficiência também para a Administração Pública.

A ordem do dia é a **produtividade**, e o Estado deve alcançar os resultados. Para tanto, mecanismos de incentivo devem existir para os servidores (e controle do desempenho deles), mas, também, a Administração terá de estar dotada de estrutura para a sua concretização.

José Afonso da Silva sustenta que “o princípio da eficiência administrativa consiste na organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas e de igualdade dos consumidores”.[8](#)

■ 22.2.6. Nepotismo

A questão do **nepotismo** vem sendo amplamente debatida na sociedade, não tendo, infelizmente, até o momento, o Congresso Nacional enfrentado, com coragem, esse palpitante tema.

O **Conselho Nacional de Justiça — CNJ**, suprimindo a inércia legislativa,

editou a **Res. n. 7/2005** (atualizada pelas Res. ns. 09/2005 e 21/2006), trazendo importantes **regras moralizadoras** em relação ao exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, contratação temporária, contratação para prestação de serviço, contratação de empresas, com as ressalvas que a referida resolução apontou, no âmbito dos órgãos do Judiciário, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

O Executivo, por sua vez, editou o **Decreto n. 7.203/2010**, dispondo sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal direta e indireta.

Existem várias propostas de emenda à Constituição tramitando, projetos de lei, mas, conforme visto, a atuação do Legislativo está deixando a desejar.

O STF, por seu turno, decidiu, na ADC 12, que a Resolução do CNJ é constitucional. Vejamos:

“EMENTA: (...) 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução n. 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos **princípios** da **impressoalidade**, da **eficiência**, da **igualdade** e da **moralidade**. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, *caput*, junte essa organização aos princípios “estabelecidos” por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça (...)”.

Devemos destacar a edição da **SV 13/STF**, ampliando a proibição do nepotismo no âmbito de todos os “Poderes”:

“A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3.º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, **viola a CF**”.

■ 22.3. “PEC PARALELA DA PREVIDÊNCIA” (EC N. 47/2005)

■ 22.3.1. Notas introdutórias

A **EC n. 47/2005** é fruto da aprovação da denominada “**PEC Paralela da Previdência**”, que recebeu os ns. 227/04-CD e 77-A/03, de 22.03.2005, do SF, elaborada à época da aprovação da **Reforma da Previdência (EC n. 41/2003)**, com o objetivo de **amenizar, melhorando as regras de transição, o seu impacto** em relação àqueles que estariam sendo surpreendidos pelas novas disposições.

Vale lembrar que o STF considerou constitucional, com as ressalvas do voto condutor do Ministro Peluso, a taxação de inativos, diante da ideia de “financiamento da seguridade social” ou do “princípio estrutural da solidariedade”, conforme se verificou no julgamento das ADIs 3.105 e 3.128.

Como percebemos, a técnica das “PECs Paralelas” vem sendo largamente utilizada pelo Congresso Nacional, sempre que, em nome de agilização das votações, se aprova a matéria consensual, deixando para discutir as modificações em novas PECs, as quais, para facilitar a análise, recebem, normalmente, o mesmo número, acrescentado de uma letra.

Já chegamos a questionar a adequação desse procedimento, mas, hoje, especialmente a partir das *Reformas da Previdência, Tributária* e do *Judiciário*, a técnica do “fracionamento” vem sendo largamente aceita, tanto pelo Congresso Nacional, que a implementa, como pelo STF.

Isso porque, como se sabe, sempre que uma Casa altera a redação de qualquer texto, em nome do **princípio do bicameralismo federativo**, a matéria terá de, necessariamente, ser reapreciada pela outra Casa, sob pena da caracterização de vício formal de inconstitucionalidade.

Para se ter um exemplo, citamos o julgamento da **ADI 3.472-MC/DF** (Rel. Min. Sepúlveda Pertence — *vide Inf. 385/STF* e a íntegra da decisão no *Inf. 392/STF*), pelo qual o STF determinou a suspensão da eficácia das expressões “e do Ministério Público”, “respectivamente” e “e ao Ministério Público da União”, contidas no § 1.º do art. 5.º da EC n. 45/2004, na medida em que o Senado Federal teria alterado substancialmente o texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

Cabe observar que a “PEC Paralela da Previdência” foi novamente “retalhada”, em relação a alguns pontos divergentes,⁹ tendo em vista o encaminhamento da **PEC n. 77-B/05-SF**, já aprovada em dois turnos no SF e encaminhada para a CD, em que levou o n. **441/2005** e está tramitando. Podemos falar agora, então, em uma “PEC Paralela da Paralela”!

Passemos, então, a analisar as principais novidades trazidas pela **EC n. 47/2005**.

■ 22.3.2. Teto do funcionalismo (art. 37, §§ 11 e 12)

■ 22.3.2.1. Regras gerais

Conforme já escrevemos neste estudo (cf. *item 9.13.3.6*), nos termos do inciso XI do art. 37 na redação dada pela **EC n. 41/2003** (*Reforma da Previdência*), a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, **incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer**

outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos **Ministros do Supremo Tribunal Federal**, aplicando-se como limite, nos **Municípios**, o subsídio do **Prefeito**, e nos **Estados** e no **Distrito Federal**, o subsídio mensal do **Governador** no âmbito do **Poder Executivo**, o subsídio dos **Deputados Estaduais e Distritais** no âmbito do **Poder Legislativo** e o subsídio dos **Desembargadores do Tribunal de Justiça**, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF, no âmbito do **Poder Judiciário**, aplicável esse limite aos membros do MP, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.

O art. 37, § 9.º, acrescentado pela EC n. 19/98, estabelece que o disposto no inciso XI do art. 37 aplica-se às **empresas públicas** e às **sociedades de economia mista**, e suas **subsidiárias**, que **receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios** para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Abrandando a regra geral do art. 37, XI (que incluía no teto as “... **vantagens pessoais** ou de **qualquer outra natureza**”), a **EC n. 47/2005**, inserindo o § 11 no art. 37, determinou não serem computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as **parcelas de caráter indenizatório previstas em lei**. Trata-se de norma de eficácia limitada que, contudo, tem efetividade e efeitos em razão da regra de integração prevista no art. 4.º da EC n. 47/2005.

Isso porque, segundo essa regra de transição, “enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do *caput* do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, **assim definida pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional n. 41, de 2003**”.

Como outra medida no sentido de **amenizar** o impacto da **Reforma da Previdência** (EC n. 41/2003) e em fortalecimento da **autonomia federativa**, a EC n. 47/2005 introduziu o § 12 no art. 37, permitindo que os Estados e o DF, por critérios de conveniência e oportunidade, fixem, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, um **teto único** equivalente

ao subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF. Essa regra, contudo, não se aplica aos Deputados Estaduais, Distritais e Vereadores.

José Afonso da Silva já havia observado que a regra da EC n. 47/2005 teria limitado a autonomia dos Estados e do DF, afrontando o art. 60, § 4.º, I. Em suas palavras, “... o texto quer apanhar qualquer situação pecuniária, por isso é minucioso, explicativo. ‘Subsídio em espécie’ significa o que é percebido em dinheiro pelo agente político. Não se leva em conta o fundo discriminatório que subjaz à norma. Um professor de centros de excelência como a USP e a UNICAMP fica sujeito a um teto fixado por critérios políticos, que é o subsídio, em espécie, do governador — que, para si e sua família, não tem despesa com moradia, não tem despesa com alimentação, não tem despesa com tinturaria, nem com médico, nem com dentista, porque tem tudo, à sua disposição, no Palácio, não digo gratuitamente, porque são formas de salário indireto; razão por que seu subsídio *em espécie*... pode ser o mais irrisório possível, porque dele não precisa para viver, porque o grosso de seu estipêndio é *em gênero* (moradia, alimentação etc.)...”.[10](#)

Cumprindo ainda observar que, nos termos do art. 8.º da EC n. 41/2003, até que fosse estabelecido o teto do funcionalismo por lei federal ordinária de iniciativa do Presidente do STF (art. 96, II, “b” — competência do STF, sendo que o Projeto de Lei se iniciaria na Câmara dos Deputados), aprovada pelo Congresso Nacional (art. 48, XV), este seria o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação da Emenda, nos exatos termos da nova redação conferida ao inciso XI do art. 37, acima reproduzida, lembrando, ainda, a previsão dos subtetos.

Em 05.02.2004, em *Sessão Administrativa* convocada pelo então Presidente do STF, Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do *Processo Administrativo n. 319.269*, ficou estabelecido que o teto salarial do STF (até que viesse a lei) seria de **R\$ 19.115,19**.

Três foram as hipóteses analisadas pelos Ministros: **a) R\$ 17.343,71** — subsídio básico dos Ministros do STF; **b) R\$ 19.115,19** — valor recebido pelo

Presidente do STF, já que o Decreto-lei n. 1.525/77, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 1.604/78, manda acrescentar à representação mensal devida ao Presidente da Corte o percentual de 20%, correspondente a R\$ 1.771,48; **c) R\$ 23.213,89** — valor decorrente da *gratificação de presença* devida na forma da Lei n. 8.350/91 [11](#) e pago aos Ministros do STF que atuam perante do TSE (art. 119, I, “a”, da CF/88).

Assim, conforme visto, em cumprimento ao art. 8.º da EC n. 41/2003, até que viesse a lei, o teto máximo do funcionalismo seria o valor pago ao Ministro Presidente do STF, de **R\$ 19.115,19**.

No referido julgamento, o Tribunal entendeu, contudo, que os três Ministros que acumulam função perante o TSE **não** terão os seus vencimentos reduzidos, já que, por determinação constitucional, recebem **gratificação especial**, não podendo uma regra fixar a acumulação (de cargos e vencimentos) e a outra proibi-la.

Em suas justificativas para a não redução no que respeita aos Ministros do TSE, o Min. Maurício Corrêa assim se manifestou: “invoco a praxis da interpretação harmônica e teleológica do texto constitucional para concluir que, na **situação particular** da acumulação dos cargos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, autorizada e mesmo determinada pelo artigo 119 da Constituição, não se aplica a cumulação das remunerações para fixação do teto ou, em outras palavras, as remunerações respectivas, para fins da aplicação do inciso XI do artigo 37, que deverão, nesse caso específico, ser consideradas isoladamente. Somente estarão sujeitas à redução se, em uma ou outra situação, *per se*, ultrapassar o limite fixado pela EC 41/2003. É claro que tal raciocínio se aplica, por decorrência lógica, a todas as situações de composição da Justiça Eleitoral” (cf. íntegra do voto: *Notícias STF*, 10.02.2004 — 15h48).

Posteriormente, a teor do art. 96, II, “b”, o PL n. 4.651/2004, de iniciativa do Presidente do STF, fixou o teto em **R\$ 21.500,00**, a partir de 1.º.01.2005, e **R\$ 24.500,00**, a partir de 1.º.01.2006 (*Notícia STF*, 21.12.2004 — 17h36). Referido projeto de lei foi convertido na **Lei n. 11.143**, de 26.07.2005, que

entrou em vigor na data de sua publicação.

Tendo em vista o aumento de 5% conferido pela Lei n. 12.041, de 08.10.2009, a partir de 1.º.09.2009, o subsídio mensal dos Ministros do STF, e, assim, o teto do funcionalismo passou a ser de R\$ 25.725,00, sendo que, também em razão do aumento de 3,88% previsto na referida lei, a partir de 1.º.02.2010, o valor passou a ser de **R\$ 26.723,13**.

Finalmente, as **Leis ns. 12.771/2012** e **13.091/2015** estabeleceram novos valores para o subsídio de Ministros do STF e, portanto, para o teto do funcionalismo (cf. *item 11.10*). Vejamos:

- **R\$ 28.059,29:** a partir de 1.º.01.2013;
- **R\$ 29.462,25:** a partir de 1.º.01.2014; e
- **R\$ 33.763,00:** a partir de 1.º.01.2015.

■ **22.3.2.2. Importantes questões já decididas pelo STF**

■ **Ministros aposentados do STF**

Quatro ministros aposentados do Supremo contestaram, via mandado de segurança (MS 24.875), a redução de seus proventos de aposentadoria ao limite constitucional fixado no art. 37, XI, da CF/88, na redação dada pela EC n. 41/2003.

Conforme ementa da apertada votação (6 x 5) “... magistrados: acréscimo de 20% sobre os proventos da aposentadoria (art. 184, III, da L. 1.711/52 c/c o art. 250 da L. 8.112/90) e o teto constitucional após a EC 41/2003: garantia constitucional de **irredutibilidade de vencimentos**: intangibilidade. Não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito adquirido de estatura constitucional, razão por que, após a EC 41/2003, não seria possível assegurar sua percepção indefinida no tempo, fora ou além do teto a todos submetido, aos impetrantes, porque magistrados, a Constituição assegurou diretamente o direito à irredutibilidade de vencimentos — modalidade qualificada de direito adquirido, oponível às emendas constitucionais mesmas. **Os impetrantes — sob o pálio**

da garantia da irredutibilidade de vencimentos —, têm direito a continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos, até que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado em lei para o Ministro do Supremo Tribunal Federal” (MS 24.875, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.05.2006, DJ de 06.10.2006 — cf., também, *Inf. 416/STF*).

■ **Fixação de novo teto remuneratório dos membros e servidores do MP por Resolução do CNMP. Inconstitucionalidade. Limite de subsídio e remuneração confirmados em 90,25% dos Ministros do STF**

A Res. n. 15, de 04.12.2006, do CNMP alterou o teto remuneratório dos membros do MP de 90,25% para 100% do subsídio de Ministros do STF.

O PGR ajuizou a **ADI 3.831** atacando a referida Res. n. 15/2006 do CNMP, que, conforme visto, alterando os arts. 1.º e 2.º da Res. n. 9/2006 e o art. 2.º da Res. n. 10/2006, ambas do CNMP, equiparava o teto remuneratório dos membros e servidores do Ministério Público da União e dos Estados ao dos Ministros do STF.

Em julgamento cautelar, o STF entendeu que a Res. n. 15/2006 citada, “... a princípio, ofende os arts. 37, X, XI, § 12, e 130-A, § 2.º, todos da CF, porquanto não observa o princípio da legalidade específica para a definição dos valores a serem pagos a título de remuneração ou subsídio dos agentes públicos, bem como extrapola os limites tanto de subsídio e remuneração previstos para os membros e servidores do Ministério Público dos Estados — 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF — quanto de competência do CNMP” (ADI 3.831-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15.12.2006 — *Inf. 452/STF*).

O STF, em **04.06.2007**, tendo em vista a revogação da Res. n. 15/2006, pela Res. n. 17/2007, declarou prejudicada a ADI.

■ **STF iguala teto remuneratório no Poder Judiciário. Juízes estaduais e juízes federais — “teto remuneratório” equivalente a 100% dos Ministros do STF. Mantido o “teto de subsídio” em 90,25% do subsídio dos Ministros do STF**

A AMB ajuizou a [ADI 3.854](#), questionando o art. 1.º da EC n. 41/2003, o art. 2.º da Res. n. 13 e o parágrafo único do art. 1.º da Res. n. 14, ambas do CNJ.

O STF, seguindo o voto [12](#) do relator, Ministro Cezar Peluso, por maioria, deferiu liminar, nos termos do art. 10, § 3.º, da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, “... para, dando interpretação conforme à Constituição ao art. 37, inc. XI, e § 12, da Constituição da República, o primeiro dispositivo, na redação da Emenda Constitucional n. 41/2003, e o segundo, introduzido pela Emenda Constitucional n. 47/2005, **excluir a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração**, bem como para suspender a eficácia do art. 2.º da Resolução n. 13/2006 e do art. 1.º, § único, da Resolução n. 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (grifamos) **(matéria pendente de julgamento pelo STF)**.

Segundo veiculado em *Notícias STF*, 28.02.2007 — 18h52, referida decisão “... não aboliu os subtetos constitucionais de subsídios, mas apenas estendeu o mesmo **teto de remuneração** (a soma do valor dos subsídios mais alguma vantagem funcional reconhecida pela ordem constitucional) das ‘justiças federais à magistratura estadual’. Salientou que o **teto remuneratório** a ser aplicado ‘corresponde ao valor do subsídio dos membros do STF’. O ministro Cezar Peluso ressaltou que ‘quando haja direito de acrescer ao subsídio, já limitados, alguma vantagem lícita, esse total não pode ultrapassar o valor do subsídio dos membros do STF, cujo valor é também, nesse sentido, teto de remuneração’”.

E continua a explicação bastante didática: “o valor recebido pelos ministros do STF possui duas funções, uma é de subsídio pago aos ministros da Corte pelo desempenho de suas funções. A outra, é a de teto remuneratório, ou seja, valor máximo a ser recebido no serviço público. ‘A decisão, pois, não aboliu os limites de subsídio dos membros dos tribunais superiores e dos desembargadores federais e estaduais. Antes da decisão, o teto da remuneração dos juízes da União, correspondendo ao valor do subsídio do STF, era maior que o dos juízes estaduais’, afirma Peluso. Os ministros entenderam que essa diferença não se justifica, uma vez que o Poder Judiciário brasileiro é um só (uno). Portanto é

incabível um tratamento desigual entre os juízes federais e estaduais”.

Nesse sentido, buscou-se harmonizar o art. 37, XI, com o art. 93, V, da CF/88, diferenciando **subsídio**, que permanece para a Magistratura estadual, equivalente a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF (art. 37, XI), de **teto de remuneração da Magistratura estadual**, que foi fixado em valor idêntico ao da Magistratura federal (art. 93, V — **princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade**), qual seja, equivalente a 100% do subsídio dos Ministros do STF, como determina o art. 37, XI.

O STF, em 08.10.2008, reconheceu conexão entre a **ADI 3.854** e a **ADI 4.014** e, portanto, determinou, na forma do art. 103 do CPC/73, a reunião dos feitos para tramitação e julgamento conjuntos. Em 03.06.2009, os autos voltaram da PGR com parecer favorável (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

■ **Aumento de 91% dos salários de parlamentares por ato administrativo conjunto das Mesas Diretoras — violação ao “devido processo legislativo”**

Ato administrativo conjunto das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado que concedeu reajuste salarial de 91% aos parlamentares federais, aumentando de R\$ 12.847,20 para R\$ 24.500,00 e, assim, equiparando ao teto remuneratório para o funcionalismo, subsídio pago aos Ministros do STF.

Os Deputados Carlos Sampaio (PSDB/SP), Fernando Gabeira (PV/RJ) e Raul Jungmann (PPS/PE) impetraram o **MS 26.307**, contestando o ato administrativo, na medida em que foram tolhidos de poder discutir sobre o aumento e se manifestar contrariamente.

Foi, também, ajuizada a **ADI 3.833** pelo PPS, com pedido de liminar.

Em relação à ADI, o STF não conheceu, na medida em que o ato atacado e que fundamentava o reajuste salarial, qual seja, o Decreto Legislativo n. 444/2002, valeria apenas para a 52.^a Legislatura, e não para a 53.^a, que se iniciava.

Com base nesse entendimento, no tocante ao MS 26.307, “... o Tribunal

deferiu pedido de liminar..., para que as Mesas da Câmara e do Senado se abstenham de editar qualquer ato que fixe subsídios de Deputados e Senadores com base no Decreto Legislativo n. 444/2002. (...) o Tribunal reconheceu a legitimidade dos impetrantes, haja vista estarem os parlamentares atuando na defesa da prerrogativa de participar de votação de matéria que, conforme o art. 49, VII, da CF, cabe ao plenário das Casas do Congresso Nacional. No mérito, entendeu-se estarem presentes os requisitos do *fumus boni iuris*, consubstanciado na aparente violação ao art. 49, VII, da CF/88, e do *periculum in mora*, representado pela iminência da efetivação do reajuste impugnado” (MS 26.307-MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 19.12.2006).

Ou seja, nada impede que se aumente o subsídio dos Deputados e Senadores, contudo deverá ser por meio de novo decreto legislativo, com base no art. 49, VII.

QUADRO COMPARATIVO DO TETO DO FUNCIONALISMO	
Teto e subtetos	Regra
■ REGRA GERAL: Subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF — parâmetro para o funcionalismo ■ nos termos do art. 37, § 11 (EC n. 47/2005), não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do art. 37, as parcelas de caráter indenizatório	■ a partir de 31.12.2003 — R\$ 19.115,19 (EC n. 41/2003); ■ a partir de 1.º.01.2005 — R\$ 21.500,00 (Lei 11.143/2005); ■ a partir de 1.º.01.2006 — R\$ 24.500,00 (Lei 11.143/2005). ■ a partir de 1.º.09.2009 — R\$ 25.725,00 (Lei 12.041/2009); ■ a partir de 1.º.02.2010 — R\$ 26.723,13 (no art. 1.º, II, da Lei 12.042/2009); ■ a partir de 1.º.01.2013 — R\$ 28.059,29

previstas em lei (vide, outrossim, art. 4.º da EC n. 47/2005)	(Lei n. 12.771/2012); ■ a partir de 1.º.01.2014 — R\$ 29.462,25 (Lei n. 12.771/2012); ■ a partir de 1.º.01.2015 — R\$ 33.763,00 (Lei n. 13.091/2015).
■ no âmbito do Poder Executivo Estadual	■ subsídio mensal do Governador do Estado
■ no âmbito do Poder Executivo Distrital	■ subsídio mensal do Governador do DF
■ no âmbito dos Municípios	■ subsídio do Prefeito
■ no âmbito do Poder Legislativo Estadual	■ subsídio mensal dos Deputados Estaduais
■ no âmbito do Poder Legislativo Distrital	■ subsídio mensal dos Deputados Distritais
■ no âmbito do Poder Judiciário Estadual e Distrital; MP, Procuradores e Defensores Públicos Estaduais e Distritais	■ Subsídio mensal dos Desembargadores de TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF
	■ fica facultado aos Estados e ao DF fixar, em seu âmbito , mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único , o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros

■ EC n. 47/2005 — art. 37, § 12	do STF; ■ esta regra não se aplica aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. ■ em nosso entender, os subsídios mensais dos Deputados Estaduais e Distritais (que não podem aplicar a regra do novo art. 37, § 12) continuam sendo o subteto para o âmbito do Poder Legislativo Estadual e Distrital, respectivamente; ■ o teto para os Vereadores continua sendo o subsídio do Prefeito; ■ a faculdade, portanto, está, ao que parece, direcionada para o âmbito do Executivo Estadual e Distrital; ■ isso porque, além do exposto, no âmbito do Poder Judiciário Estadual e Distrital, MP, Procuradores e Defensores Públicos Estaduais e Distritais, o teto já era este dos Desembargadores do TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF.
■ ADI 3.854 — julgamento liminar (28.02.2007)	■ o STF iguala teto remuneratório no Poder Judiciário. Juízes estaduais e juízes federais — “teto remuneratório” equivalente a 100% dos Ministros do STF. Mantido o “teto de subsídio” em 90,25% do subsídio dos Ministros do STF.

■ 22.3.3. Aposentadorias especiais (arts. 40, § 4.º, I, II e III, e 201, § 1.º)

O art. 40, § 4.º, da CF/88, em sua redação dada pela **EC n. 47/2005**, estabelece ser vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em **leis complementares**, os casos de **servidores**:

- **portadores de deficiência;**
- **que exerçam atividades de risco;**
- **cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.**

As duas primeiras hipóteses foram introduzidas pela EC n. 47/2005.

Em relação à primeira novidade (**servidores portadores de deficiência**), tivemos a consagração das denominadas discriminações positivas, tratando desigualmente pessoas desiguais para que, nessa atividade prestacionista do Estado, se chegasse a uma igualdade real, substancial ou material.

Cabe observar que essa regra foi prevista de forma expressa tanto para o regime próprio dos **servidores públicos** como para os segurados do **regime geral da previdência social**, conforme inclusão também feita ao art. 201, § 1.º, do seguinte teor: “é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e **quando se tratar de segurados portadores de deficiência**, nos termos definidos em lei complementar”.

Lembramos que a **LC n. 142/2013** regulamentou a Constituição no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do *Regime Geral de Previdência Social (RGPS)*. Sem dúvida, até que a matéria seja estabelecida também para o funcionalismo público, referido ato normativo poderá servir de parâmetro para eventuais decisões em mandado de injunção (art. 40, § 4.º — *regulamentação pendente*).

O STF, em alguns poucos casos já apreciados (poucos em comparação às discussões envolvendo o inciso III), determinou a aplicação analógica da referida lei complementar para regulamentar o direito fundamental de servidores públicos portadores de deficiência (cf., por exemplo, o **MI 1.885-AgR**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.05.2014, Plenário, *DJE* de 13.06.2014).

Percebe-se, dessa forma, de maneira inovadora, que a diferenciação nesse primeiro caso decorre da **situação da pessoa**, e não da modalidade da atividade desenvolvida, o que é um avanço.

Em relação à segunda novidade introduzida pela EC n. 47/2005 (servidores que **exerçam atividades de risco**), podemos lembrar, para se ter um exemplo, a situação particular dos servidores públicos policiais. Embora se possa dizer que eles já estivessem englobados pela regra do art. 40, III (atividades que prejudiquem a integridade física), muito bem-vinda a novidade, já que explicita a hipótese de aposentadoria especial, sem deixar qualquer tipo de dúvida.

Sobre essa específica categoria de servidores, destacamos a **LC n. 51/85**, recepcionada pela CF/88 e modificada pela **LC n. 144/2014**, que regulamenta a aposentadoria especial do servidor público policial.

O tema, em relação a outras categorias de servidores, vem sendo enfrentado pelo STF que discute a distinção entre o **risco permanente** (inerente ao policial civil, por exemplo), do **risco eventual** (a questão envolve a categoria dos oficiais de justiça — cf. **MI 833** e **844**, *pendentes de julgamento*).

Finalmente, em relação aos servidores cujas **atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física** — e que já estava prevista essa garantia na redação original da Constituição, o STF enfrentou a omissão do Poder Legislativo (ainda observada quando do fechamento desta edição), no julgamento de vários mandados de injunção.

Após **reiteradas decisões** sobre essa matéria constitucional — art. 40, § 4.º, III, (cf., por exemplo, MI 721, MI 795, MI 788, MI 925, MI 1.328, MI 1.527, MI 2.120, MI 1.785, MI 4.158 AgR-segundo, MI 1.596 AgR, MI 3.215 AgR-segundo), o **STF** aprovou a *PSV 45* e, assim, editou, em 09.04.2014, a **SV 33**, com o seguinte teor: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras

do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4.º, inciso III da Constituição Federal, **até a edição de lei complementar específica**” (DJE de 24.04.2014). [13](#)

■ 22.3.4. Aumento da faixa de isenção de contribuição previdenciária para os servidores inativos e os pensionistas que sejam, nos termos da lei, portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21)

De acordo com o art. 40, § 21, a contribuição prevista no § 18, qual seja, aquela sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime especial dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que **superem o dobro** do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição, **quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante**.

Cuida-se de mais um importante avanço, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, devendo a lei definir o que deva ser entendido por **doença incapacitante**.

■ 22.3.5. Ampliação das hipóteses de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas das contribuições sociais para o financiamento da seguridade social (art. 195, § 9.º)

O art. 195, *caput*, e inciso I da CF/88, dispõem que a **seguridade social** será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, dentre outras, das **contribuições sociais do empregador**, da **empresa** e da **entidade a ela equiparada na forma da lei**, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem

vínculo empregatício; a receita ou o faturamento; o lucro.

E o § 9.º do art. 195, por seu turno, estabelece que as referidas contribuições do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei poderão ter **alíquotas** ou **bases de cálculo diferenciadas**, em razão da **atividade econômica**, da **utilização intensiva de mão de obra**, do **porte da empresa** ou da **condição estrutural do mercado de trabalho**.

Essas duas últimas situações (porte da empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho) são as novidades trazidas pela EC n. 47/2005 em relação à possibilidade de se fixarem alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas.

■ 22.3.6. Ampliação do sistema especial de inclusão previdenciária (art. 201, §§ 12 e 13)

Nos termos do art. 201, § 12, a lei disporá sobre o **sistema especial de inclusão previdenciária** para atender a trabalhadores de baixa renda e **àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda**, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo.

O sistema especial de inclusão previdenciária já havia sido introduzido pela **EC n. 41/2003**, consagrando importante medida de **ação afirmativa**.

A **EC n. 47/2005** implementa o sistema ao ampliar a possibilidade de inclusão para os trabalhadores sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao **trabalho doméstico** no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a **famílias de baixa renda**.

Outra importante novidade trazida pela “PEC Paralela da Previdência” foi a ampliação da inclusão social também em relação ao benefício da **aposentadoria por tempo de contribuição**, único vedado pela regra anterior.

Assim, muito embora ainda **dependa de lei** que crie e implemente o sistema, o acesso será a **todo e qualquer benefício previdenciário**, sem exceção, abrangendo, inclusive, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que respeitando o valor de um salário mínimo.

Por fim, é de destacar que o sistema especial de inclusão previdenciária terá **alíquotas** e **carências inferiores** às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social (art. 201, § 13). Essa regra permite concluir que os aludidos segurados também contribuirão para o financiamento da seguridade social, só que de maneira diferenciada, nos termos da lei, tratando-se desigualmente os desiguais.

■ 22.3.7. Paridade plena entre ativos e inativos (arts. 2.º e 5.º da EC n. 47/2005)

Na dicção do art. 2.º da **EC n. 47/2005**, aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do *caput* do art. 6.º da EC n. 41/2003 (regra que consagrou o instituto da “reserva de direitos” ou dos “direitos adquiridos *in fieri*” [14](#)) o disposto no art. 7.º da mesma Emenda: a **paridade plena com os servidores em atividade**.

Essa regra de **aposentadoria com proventos integrais**, regra de **transição**, vale para o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da EC n. 41/2003, isto é, até **31.12.2003**.

Observe-se que a integralidade, que persiste com a EC n. 47/2005 (conferir regras do art. 40 da CF e art. 6.º — EC n. 41/2003), já era prevista pela EC n. 41/2003, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições (servidores que tenham ingressado até 31.12.2003):

- 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;
- 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;
- 20 anos de efetivo exercício no serviço público; e
- 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

A novidade trazida pela EC n. 47/2005 está na **garantia da paridade plena** com os servidores em atividade, especialmente nos termos do seu art. 5.º, que revoga o parágrafo único do art. 6.º da EC n. 41/2003.

Trata-se do que muitos chamaram de o “coração da PEC Paralela”, o compromisso firmado durante a tramitação da EC n. 41/2003 para uma transição menos gravosa e com a aplicação da regra da paridade.

Cumprе registrar que durante a tramitação da “PEC Paralela” houve a supressão da paridade plena para os **pensionistas**, situação essa constante agora na “PEC Paralela da Paralela”, qual seja, a PEC n. 77-B/05-SF, que foi aprovada em dois turnos no Senado Federal, e agora tramita sob o n. 441/2005 na Câmara dos Deputados.

■ 22.3.8. Regra geral de transição (art. 3.º da EC n. 47/2005)

Consoante o **art. 3.º da EC n. 47/2005**, ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da CF/88 ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2.º e 6.º da EC n. 41/2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até **16.12.1998** (data da publicação da EC n. 20/98), poderá **aposentar-se com proventos integrais**, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

- 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;
- 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria;
- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, III, “a”, da Constituição Federal, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput* deste artigo.

O parágrafo único do art. 3.º da EC n. 47/2005 estabelece aplicar-se ao valor

dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7.º da EC n. 41/2003 (**paridade plena**), observando-se igual critério de revisão às **pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos** que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

■ 22.3.9. Vigência da EC n. 47/2005 (art. 6.º)

Estabelece o art. 6.º que a EC n. 47/2005 entra em **vigor** na **data de sua publicação**, com **efeitos retroativos à data de vigência** da EC n. 41/2003, isto é, **31.12.2003** (data da publicação da *Reforma da Previdência*).

Conforme observa o relator da Reforma, Senador Rodolpho Tourinho, no *Parecer n. 1.032/2005* da CCJC, a regra é muito bem-vinda, “... uma vez que o objetivo inicial da ‘PEC Paralela’ foi o de amenizar alguns dos efeitos da Reforma da Previdência que não puderam ser inseridos na EC n. 41, de 2003...”.

■ 22.4. EC N. 55/2007

Na medida em que o tema tratado não interfere em nosso trabalho de modo direto, remetemos o nosso ilustre leitor para os livros de direito tributário e financeiro, pedindo vênias para simplesmente indicar as novidades.

A **EC n. 55/2007** aumentou em 1% o repasse na repartição de receitas tributárias indicando como destinatário o Fundo de Participação dos Municípios (art. 159, I, “d”).

■ 22.5. “PEC DOS AGENTES DE SAÚDE” — EC N. 63/2010

A **EC n. 63/2010** é fruto da conversão da **PEC n. 54/2009**, conhecida como “**PEC dos Agentes de Saúde**”.

Estamos diante de importante conquista, abrindo caminho para que se fixem piso salarial nacional e planos de carreiras dos agentes de saúde.

A disciplina do piso nacional passa a ser atribuída à **União** e não mais vinculada aos Estados, DF e Municípios.

Essa novidade segue a linha do que se estabeleceu para os **professores** do Brasil (art. 206, VIII, introduzido pela EC n. 53/2006): “o ensino fundamental será ministrado com base nos seguintes princípios: piso salarial profissional **nacional** para os profissionais da **educação escolar pública**, nos termos de **lei federal**”.

Assim, pedimos vênua para citação da novidade introduzida pela referida **EC n. 63/2010**:

“Art. 198. (...)”

§ 5.º **Lei federal** disporá sobre o **regime jurídico**, o **piso salarial** profissional **nacional**, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de **agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias**, competindo à **União**, nos termos da **lei**, prestar **assistência financeira complementar** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (...)”

■ 22.6. EC N. 70/2012

Uma vez que o tema não interfere diretamente em nosso trabalho, remetemos o nosso ilustre leitor para os livros de direito administrativo e previdenciário. Aqui, pedimos vênua para apenas transcrever a EC n. 70/2012:

“Art. 1.º A Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6.º-A:

‘Art. 6.º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1.º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3.º, 8.º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no *caput* o disposto no art. 7.º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores’.

Art. 2.º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1.º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1.º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

■ 22.7. EC N. 75/2013

A **EC n. 75/2013** acrescentou a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo **imunidade tributária** sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham.

Assim como o item anterior, remetemos o nosso ilustre leitor para os livros específicos de direito tributário.

■ 22.8. EC N. 84/2014

Assim como já havia feito a EC n. 55/2007, a referida **EC n. 84/2014** também alterou o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios.

O tema, naturalmente, dado o objetivo deste trabalho e a sua especificidade, deverá ser estudado nos livros de direito tributário e financeiro.



REFERÊNCIAS

- ABELHA RODRIGUES, Marcelo. *Elementos de direito processual civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 2.
- . *Suspensão de segurança*: sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
- ACCIOLY, Hildebrando. *Manual de direito internacional público*. Atualizado por Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva e Paulo Borba Casella. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- AGRA, Walber de Moura. *A reconstrução da legitimidade do Supremo Tribunal Federal*: densificação da jurisdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- . *Fraudes à Constituição*: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2000.
- . *Curso de direito constitucional*. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- ALEGRE, José Sérgio Monte. A ação popular como instrumento de participação popular. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 189, p. 123-138.
- ALEXY, Robert; SILVA, Luis Virgílio Afonso da (Trad.). *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.
- ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. A Constituição do Estado federal e das unidades federadas. *Revista de Informação Legislativa*, v. 24, n. 95, p. 171-82, jul./set. 1987.
- . A incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro: análise do tema à luz do direito constitucional. *Revista do Advogado*, São Paulo, v. 23, n. 73, p. 48-58, nov. 2003.
- ; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Efeitos da Constituição sobre o direito anterior. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, jun. 1989.
- ALMEIDA NETO, Manoel Carlos de. *O novo controle de constitucionalidade municipal*. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

- ALVES, Alaôr Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas dimensões constitucionais da organização do estado brasileiro. *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*. São Paulo, número especial, p. 9-49, set. 1998.
- ALVIM NETTO, Arruda. *Direito processual civil: teoria geral do processo de conhecimento*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. v. 1.
- AMORIM, Paulo Roberto Rodrigues. *Os direitos humanos da terceira geração*. Manoel Gonçalves Ferreira Filho (orientador). São Paulo: [s.n.], 1996. 57 p. Dissertação de mestrado — Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
- ANTUNES, Luis Felipe Colaço. *A tutela dos interesses difusos em direito administrativo: para uma legitimação procedimental*. Coimbra: Almedina, 1989.
- ARAUJO, Julyver Modesto de. *Emenda constitucional dos agentes de trânsito*. Disponível em: <<http://www.ctbdigital.com.br>>, comentários ao art. 7.º. Acesso em: 10.01.2015.
- ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- ; ———. *Curso de direito constitucional*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 (6. ed., 2002; 2. ed., 1999).
- ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo”: entre a “ciência do direito” e o “direito da ciência”. *Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE)*, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, jan./mar. 2009. Disponível em: <<http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>>. Acesso em: 5 jan. 2014.
- . *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007.
- AZEVEDO, Márcia Maria Corrêa de. *Prática do processo legislativo: jogo parlamentar; fluxos de poder e ideias no Congresso; exemplos e momentos comentados*. São Paulo: Atlas, 2001.
- BACHA, Sergio Reginaldo. *Constituição Federal: leis complementares e leis ordinárias — hierarquia?* Belo Horizonte: Fórum, 2004.
- . *Mandado de injunção*. Belo Horizonte: Del Rey, 1997.
- BACHOF, Otto. *Normas constitucionais inconstitucionais?* Coimbra: Almedina, 1994.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973*. 12. ed. rev. e atual. (inclusive de acordo com o novo Código Civil e com a Emenda Constitucional n. 45). Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 5 (arts. 476 a 565).
- . Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. *Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, n. 62, p. 43-68,

jan./mar. 2005.

———. *Litisconsórcio unitário*. Rio de Janeiro: Forense, 1972.

———. *Questões prejudiciais e coisa julgada*. Rio de Janeiro: [s. n.], 1967. 132 p. Tese de livre-docência — Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

———. *Temas de direito processual*. São Paulo: Saraiva, 1977.

BARBOSA, Rui. *Actos inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a justiça federal*. Rio de Janeiro: Imprensa, 1893.

———. *Oração aos moços*: edição comemorativa do centenário de nascimento do grande brasileiro. São Paulo: Reitoria da Universidade de São Paulo, 1949. v. 1. (Fac-símile do texto original, datilografado e contendo emendas do próprio punho do autor.)

BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, abr./jun. 2005.

———. *Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

BARROSO, Luis Roberto. *Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade*. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art_03-10-01.htm##LS>. Acesso em: 1.º.01.2015.

———. *Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

———. Disposições constitucionais transitórias (natureza, eficácia e espécies); delegações legislativas (validade e extensão); poder regulamentar (conteúdo e limites). In: CLÈVE, Clèmerson Merlin; BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Doutrinas essenciais direito constitucional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 489-505.

———. *Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004.

———. Liberdade de expressão *versus* direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. In: *Temas de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. t. III, p. 79-130.

———. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência*. São Paulo: Saraiva, 2004.

———. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira*. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

- . Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 102, n. 384, p. 71-104, mar./abr. 2006.
- . *Temas de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito constitucional*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.
- . *Hermenêutica e interpretação da Constituição*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos, Editor, 2002.
- ; BRITTO, Carlos Ayres. *Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais*. São Paulo: Saraiva, 1982.
- ; TAVARES, André Ramos. *As tendências do direito público no limiar de um novo milênio*. São Paulo: Saraiva, 2000.
- . Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 102, n. 384, p. 71-104, mar./abr. 2006.
- . *Temas de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- BAYÓN, Juan Carlos; RODRÍGUEZ RUSSO, Jorge. *Relevancia normativa en la justificación de las decisiones judiciales: el debate Bayón-Rodríguez sobre la derrotabilidad de las normas jurídicas*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003 (também em formato *e-book*).
- BECHARA, Fábio Ramazzini. *Tribunal Penal Internacional e o princípio da complementaridade*. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, dez. 2003. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- ; CAMPOS, Pedro Franco de. *Princípios constitucionais do processo penal: questões polêmicas*. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, jan. 2005. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Direito e processo: influência do direito material sobre o processo*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
- . *Poderes instrutórios do juiz*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
- BENDIX, Reinhard. *Construção nacional e cidadania: estudos de nossa ordem social em mudança*.
- BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e (Coord.). *Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão*. Ada Pellegrini Grinover et al. (Colab.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 470 p. (Biblioteca de Direito ambiental, v. 2).
- BERNARDES, Juliano Taveira. Aborto de feto anencefálico e “derrotabilidade”. *Jus Navigandi*,

- Teresina, ano 10, n. 617, 17 mar. 2005. Disponível em: <<http://jus.uol.com.br/revista/texto/6466>>. Acesso em: 1.º jan. 2011 (artigo originalmente publicado no Suplemento Direito & Justiça, do jornal *Correio Braziliense*, 07.03.2005).
- . *Controle abstrato de constitucionalidade: elementos materiais e princípios processuais*. São Paulo: Saraiva, 2004.
- BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Súmulas do STF comentadas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. *O direito penal na era da globalização*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
- BINENBOJM, Gustavo. *A nova jurisdição constitucional brasileira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- BITTENCOURT, C. A. Lúcio. *O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968.
- BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
- ; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de política*. Trad. Carmem C. Varrialle et al. Coord. de tradução de João Ferreira. 7. ed. Brasília: Ed. UnB, 1995. v. 2.
- BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997.
- Brasil. Congresso. *Câmara dos Deputados. Regimento Interno da Câmara dos Deputados: aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, e alterado pelas Resoluções ns. 1, 3 e 10, de 1991; 22 e 24, de 1992; 25, 37 e 38, de 1993; 57 e 58, de 1994; 1, 77, 78 e 80, de 1995; 5, 8 e 15, de 1996; 33, de 1999; e 11, de 2000*. 5. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000 (Série Textos Básicos, n. 18).
- . *Congresso. Regimento Comum: Resolução n. 1, de 1970-CN, com alterações posteriores até 1994: legislação conexa*. Brasília: Congresso Nacional, 1977.
- . *Congresso. Senado Federal. Regimento Interno: Resolução n. 93, de 1970*. Brasília: Senado Federal, 1999. v. 2.
- . *Leis etc. Collecção das leis do Imperio do Brazil de 1827*. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1878.
- BUENO, Cassio Scarpinella. *Novo Código de Processo Civil anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. São Paulo: Saraiva, 2000.

- . *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- BURDEAU, Georges. *Traité de science politique*. 2. ed. Paris: LGDJ, 1969. v. 4.
- BURGER, Adriana Fagundes; KETTERMANN, Patrícia; LIMA, Sérgio Sales Pereira (Org.). *Defensoria Pública [recurso eletrônico]: o reconhecimento constitucional de uma metagarantia*. Dados eletrônicos. Brasília: Anadep, 2015. 283 p. Disponível em: <http://www.anadep.org.br/wtksite/AF_E-book_Metagarantia.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2015.
- BURNHAM, William. *Introduction to the law and the legal system of the United States*. St. Paul, West, Thomson Reuters, 2011.
- BUSSI, Emilio. *Evoluzione storica dei tipi di stato*. Milano: Malfasi, 1948.
- BUZAID, Alfredo. *Considerações sobre o mandado de segurança coletivo*. São Paulo: Saraiva, 1992.
- . *Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 1958.
- CAETANO, Marcelo. *Direito constitucional*. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 2.
- CALCINI, Fábio Pallaretti. *Limites ao poder de reforma da Constituição: o embate entre as gerações*. Campinas: Millennium, 2009.
- CALMON FILHO, Petrônio (Org.). *Reforma constitucional do Poder Judiciário*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Processual, jan. 2000 (Cadernos IBDP: Propostas legislativas: 1).
- . *Reforma constitucional do Poder Judiciário* (Org. Petrônio Calmon Filho). São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Processual, v. II, ago. 2001 (Cadernos IBDP: Propostas legislativas: 1).
- CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. *Constituições do Brasil: compilação e atualização dos textos*. 13. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- CAMPOS, Francisco. *Direito constitucional*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956. v. 1.
- CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. *A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos*. São Paulo: Saraiva, 1991.
- . Meio ambiente e desenvolvimento: formulação, natureza jurídica e implementação do direito ao desenvolvimento como um direito humano. *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*, Rio de Janeiro, n. 81/83, p. 49-76, jul./dez. 1992.
- ; KISS, Alexandre. Two major challenges of our time: human rights and the environment. *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*, Rio de Janeiro, n. 81/83, p. 147-150, jul./dez. 1992.
- CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. ed. rev.

- Coimbra: Almedina, 1993 (7. ed., 2003).
- . *Estudos sobre direitos fundamentais*. 1. ed. brasileira; 2. ed. portuguesa. São Paulo: Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Ed., 2008 (coedição).
- ; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 2.380 p.
- ; MOREIRA, Vital. *Constituição da República Portuguesa anotada*. 2. ed. [s. l.]: [s. n.], 1985. v. 2.
- CAPEZ, Fernando. *Curso de processo penal*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998.
- CAPPELLETTI, Mauro. *O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado*. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves; revisão de José Carlos Barbosa Moreira. 2. ed. reimpr. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1999 (reimpresso da 1. ed. de 1984.) (Tradução de *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, settima ristampa. Milano: Giuffrè, 1978).
- . *Giustizia e società*. Milano: Comunità, 1977.
- . *Juízes legisladores*. Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1988 (Trad. *Giudici irresponsabili?* Milano: Giuffrè, 1988).
- ; GARTH, Bryant. *Acesso à justiça*. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1988.
- CARBONELL, Miguel. *Neoconstitucionalismo(s)*. 4. ed. Madrid: Trotta, 2009 (Colección estructuras y procesos. Serie Derecho).
- CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96*. São Paulo: Malheiros, 1998.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e competência*. 10. ed. rev. e ampl. de conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 2000.
- CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. *O Ministério Público no processo civil e penal — promotor natural: atribuição e conflito*. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense (originalmente apresentada como tese de doutorado, sob o título: *O Ministério Público na teoria geral do processo — promotor natural: atribuição e conflito*, UERJ, 1988).
- CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de direito constitucional tributário*. 16. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 31/2000. São Paulo: Malheiros, 2001.
- CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana. *Revista Española de Derecho Internacional*, Madrid, p. 119-125, 1972.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 23. ed. rev., ampl. e

- atualizada até 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- CARVALHO, Ivan Lyra de. Mandado de segurança coletivo e partidos políticos. *Revista Trimestral de Direito Público*, v. 6, p. 200.
- CARVALHO, Kildare Gonçalves. *Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição*. Direito constitucional positivo. 12. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2006 (15. ed., 2009).
- CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000.
- CASSEB, Paulo Adib. *Processo legislativo: atuação das comissões permanentes e temporárias*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
- CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. *Direito eleitoral brasileiro*. 3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
- CHEVALLIER, Jacques. *L'état de droit*. 2. ed. Paris: Montchrestien, 1994 (Serie Clefs. Politique, 1159-2281).
- CHIMENTI, Ricardo Cunha. *Apontamentos de direito constitucional*. 2. ed. São Paulo: Paloma, 2002.
- . *Direito tributário*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002 (Coleção Sinopses Jurídicas, v. 16).
- . *Teoria e prática dos juizados especiais cíveis*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- ; CAPEZ, Fernando; ROSA, Márcio Fernando Elias; SANTOS, Marisa F. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2004 (6. ed., 2009).
- CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria geral do processo*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- CLÈVE, Clèmerson Merlin. *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
- . *Atividade legislativa do Poder Executivo no Estado contemporâneo e na Constituição de 1988*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
- . *Medidas provisórias*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Max Limonad, 1999.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Para entender Kelsen*. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, [s. d.].
- COELHO, Inocêncio Mártires. *Interpretação constitucional*. 3. ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 2007.
- COMPARATO, Fábio Konder. *A afirmação histórica dos direitos humanos*. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.
- . Réquiem para uma Constituição. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, São Paulo, Número especial, p. 51-63, set. 1998.

- CORREIA, Érica Paula Barcha. Comentário ao art. 54, ADCT. In: MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.
- COSTA, Sílvio Nazareno. *Súmula vinculante e reforma do Judiciário*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
- CRETELLA JÚNIOR, José. *Comentários à constituição brasileira de 1988*. Rio de Janeiro: Forense, [s.d.]. v. 5.
- CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Controle das omissões do Poder Público em busca de uma dogmática constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da Constituição*. São Paulo: Saraiva, 2004.
- . *Curso de direito constitucional*. Salvador: JusPodivm, 2008.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de teoria geral do estado*. 16. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1991.
- DANTAS, Ivo. *O valor da Constituição: do controle de constitucionalidade como garantia da suprallegalidade constitucional*. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- . *Poder constituinte e revolução: breve introdução à teoria sociológica do direito constitucional*. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1978. Tese defendida para obtenção do título de Mestre em Sociologia pelo Programa Integrado de Mestrado em Economia e Sociologia — PIMES — da Universidade Federal de Pernambuco — área de concentração em Sociologia Jurídica, 1976.
- DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. *Mandado de segurança coletivo: legitimação ativa*. São Paulo: Saraiva, 2000.
- DAVID, René. *Os grandes sistemas do direito contemporâneo*. Trad. Hermínio A. Carvalho. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- DERANI, Cristiane. *Direito ambiental econômico*. São Paulo: Max Limonad, 1997.
- DIAS, Maria Berenice. *União homossexual: o preconceito e a justiça*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
- DIDIER JR., Fredie. Transformações do recurso extraordinário. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). *Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
- DI GIORGI, Beatriz; CAMPILONGO, Celso Fernandes; PIOVESAN, Flávia (Coord.). *Cidadania e justiça: ensaios sobre lógica, interpretação, teoria, sociologia e filosofia jurídicas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
- DIMOULIS, Dimitri. Significado e atualidade da separação de poderes. In: AGRA, Walber de

- Moura; CASTRO, Celso Luiz Braga de; TAVARES, André Ramos (Coord.). *Constitucionalismo*. Os desafios no terceiro milênio. Belo Horizonte: Forum, 2008.
- . Uma visão crítica do neoconstitucionalismo. In: SALOMÃO, Leite George; SALOMÃO, Leite Glauco (Org.). *Constituição e efetividade constitucional*. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 43-53.
- ; DUARTE, Écio Oto Ramos (Coord.). *Teoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?* São Paulo: Método, 2008.
- ; MARTINS, Leonardo. *Teoria geral dos direitos fundamentais*. 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *A instrumentalidade do processo*. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1998.
- . A reclamação no processo civil brasileiro. *Revista do Advogado*, São Paulo, n. 61, p. 104-10. nov. 2000.
- . *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Malheiros, 2001. 3 v.
- DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito*. 8. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995.
- . *Conflito de normas*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1996.
- . *Norma constitucional e seus efeitos*. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
- . Participação popular na administração pública. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 191, p. 26-39, jan./mar. 1993.
- ; GRECO FILHO, Vicente; GASPARINI, Diogenes. Mandado de segurança, ação civil pública, ação popular. *Boletim de Direito Administrativo*, São Paulo, v. 20, n. 7, p. 731-47, jul. 2004.
- DOTTI, René Ariel. *Curso de direito penal: parte geral*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
- DROMI, José Roberto. La reforma constitucional: el constitucionalismo del “por-venir”. In: ENTERRÍA, Eduardo García de; ARÉVALO, Manuel Clavero (Coord.). *El derecho público de finales de siglo: una perspectiva iberoamericana*. Madrid: Fundación Banco Bilbao Vizcaya/Civitas, 1997.
- DUARTE, Écio Oto Ramos. *Teoria do discurso e correção normativa do direito: aproximação à metodologia discursiva do direito*. 2. ed. rev. São Paulo: Landy, 2004.
- ; POZZOLO, Susanna. *Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da Constituição*. 2. ed. São Paulo: Landy,

2010.

DWORKIN, Ronald. *Taking rights seriously*. 18. tir. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

———; BOEIRA, Nelson (Trad.). *Levando os direitos a sério*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

ENTERRÍA, Eduardo García de. Justicia constitucional: la doctrina prospectiva en la declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales. *Revista de Direito Público*, São Paulo, v. 22, n. 92, p. 5-16, out./dez. 1989.

ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. *Direito penal esquematizado: parte geral*. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

FACHIN, Luiz Edson. *Direito de família: elementos críticos à luz do novo Código Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 13-62.

FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. *El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización*, p. 139-140 (tradução livre).

———. *Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino*.

———. *Aos 20 anos da Convenção 169 da OIT: balanço e desafios da implementação dos direitos dos Povos Indígenas na América Latina*, p. 25-31.

FARIA, Cássio Juvenal. *Comissões parlamentares de inquérito*. São Paulo: Edições Paloma, 2000.

FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira (Org.). *Crise do direito numa sociedade em mudança*. Brasília: Ed. UnB, 1988.

——— (Org.). *Direito e justiça: a função social do Judiciário*. 3. ed. São Paulo: Ática, 1997.

———. *Justiça e conflito: os juízes em face dos novos movimentos sociais*. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

FAVOREU, Louis; RUBIO LLORENTE, Francisco. *El bloque de la constitucionalidad: simposium franco-español de derecho constitucional*. Madrid-Sevilla: Civitas/Universidad de Sevilla, 1991.

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. *Controle da constitucionalidade das leis municipais*. 3. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

———. *Efeitos da declaração de inconstitucionalidade*. 5. ed. rev., atual e ampl. São Paulo:

- Revista dos Tribunais, 2004 (3. ed., 1992).
- FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. *Poder constituinte dos Estados-membros*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.
- . *Processos informais de mudanças da Constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais*. São Paulo: Max Limonad, 1986.
- FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. *Revista de Direito Público*, São Paulo, n. 49-50, p. 34-41, jan./jun. 1979.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa*. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- . *Curso de direito constitucional*. 34. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.
- . *Do processo legislativo*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
- . *O poder constituinte*. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2005.
- FERREIRA, Ivette Senise. *Tutela penal do patrimônio cultural*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
- FERREIRA, Luiz Pinto. *Comentários à constituição brasileira*. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 3.
- . *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 1999.
- . *Princípios gerais do direito constitucional moderno*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1962.
- FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. A imunidade parlamentar na Emenda Constitucional n. 35, de 20 de dezembro de 2001. *Revista Diálogo Jurídico*, Salvador: CAJ — Centro de Atualização Jurídica, n. 14, jun./ago. 2002. Disponível em: <<http://www.direitopublico.com.br>>. Acesso em: 3 jan. 2003.
- . *Controle de constitucionalidade e seus efeitos*. São Paulo: Método, 2003.
- . *Sistema constitucional das crises*. Restrições a direitos fundamentais. São Paulo: Método, 2009. v. 12 (Col. Prof. Gilmar Mendes).
- ; FERNANDES, Rodrigo Pieroni. A arguição de descumprimento de preceito fundamental e a manipulação dos efeitos de sua decisão. *Revista Diálogo Jurídico*, Salvador: CAJ — Centro de Atualização Jurídica, n. 12, mar. 2002. Disponível em: <<http://www.direitopublico.com.br>>. Acesso em: 3 jan. 2003.
- FINGER, Julio César. Constituição e direito privado: algumas notas sobre a chamada constitucionalização do direito civil. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). *A Constituição*

- concretizada*: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. *Os sindicatos e a defesa dos interesses difusos no direito processual civil brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995 (Coleção Estudos de Direito de Processo em homenagem a Enrico Tullio Liebmann, n. 31; originalmente apresentada como tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1993).
- FRAGA, Mirtô. *O conflito entre tratado internacional e a norma de direito interno*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- FRANCO, Afonso Arinos de Melo (Introd.); SOUZA, Carlos Fernando Mathias de (Prefácio). *O constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal* (ed. fac-similar). Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003 (Coleção História Constitucional Brasileira).
- GARCÉS V., Fernando. Os esforços de construção descolonizada de um Estado plurinacional na Bolívia e os riscos de vestir o mesmo cavaleiro com um novo paletó. In: VERDUM, Ricardo (Org.). *Povos indígenas: Constituições e reformas políticas na América Latina*. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009. p. 167-192.
- GARNER, Bryan A. (Ed.). *Black's law dictionary*. 10 ed. St. Paul, West, Thomson Reuters, 2014.
- GIANNINI, Massimo Severo. *Diritto amministrativo*. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1993. v. 1.
- GOMES, Joaquim B. Barbosa. *Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento de transformação social — a experiência dos EUA*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- GOMES, Luiz Flávio. *A dimensão da magistratura no estado constitucional e democrático de direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
- . *A questão do controle externo do poder judiciário: natureza e limites da independência judicial no estado democrático de direito*. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- . Está nascendo o primeiro Tribunal Penal Internacional. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 6, n. 56, abr. 2002. Disponível em: <<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2920>>. Acesso em: 2 fev. 2005.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro: direito de família*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. v. VI.
- . *Direito civil esquematizado*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 1.

- GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. *Direito eleitoral*. São Paulo: Atlas, 2010 (Coleção Concursos Jurídicos, v. 18).
- . *Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988*. Belo Horizonte: Fórum, 2007 (Coleção Fórum de Direitos Fundamentais, 1).
- GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. *Direito processual civil esquematizado*. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015.
- GONÇALVES, Vitor Fernandes. *O controle de constitucionalidade das leis do Distrito Federal*. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 1999.
- GRECO FILHO, Vicente. *Acesso à justiça*. Brasília: Instituto Tancredo Neves, 1987. 8 p. (Cadernos Liberais).
- . *Tutela constitucional das liberdades*. São Paulo: Saraiva, 1989.
- GRIJALVA, Agustín. O Estado plurinacional e intercultural na Constituição equatoriana de 2008. In: VERDUM, Ricardo (Org.). *Povos indígenas: Constituições e reformas políticas na América Latina*. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009. p. 113-133.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. A ação direta de controle da constitucionalidade na Constituição paulista. *Juriscível do STF*, São Joaquim da Barra-SP, v. 5, n. 55, p. 7-19, jul. 1977.
- . *A marcha do processo*. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
- . A reclamação para garantia da autoridade das decisões dos Tribunais. *Revista de Direito da Associação dos Procuradores do novo Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 10, p. 1-9, 2002.
- . *A reforma do Poder Judiciário*. São Paulo: FIESP/CIESP, 1997 (Reunião realizada em 24.09.1996 na sede da FIESP/CIESP — Debates sem revisão dos participantes: Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Miguel Reale Junior, Octavio Bueno Magano, Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Esther de Figueiredo Ferraz).
- . A tutela jurisdicional dos interesses difusos. *Revista de Processo*, São Paulo, n. 14-15, abr./set. 1979.
- . Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 22, n. 87, p. 37-47, jul./set. 1997.
- . *As garantias constitucionais do direito de ação*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. XII.
- . Controle da constitucionalidade. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 23, n. 90, p. 11-21, abr./jun. 1998.

- . Da reclamação. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, v. 9, n. 38, p. 75-83, abr./jun. 2002.
- . *Liberdades públicas e processo penal: as interceptações telefônicas*. 2. ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. xv.
- . *Novas tendências do direito processual: de acordo com a Constituição de 1988*. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. xi (Série Biblioteca Jurídica).
- . O controle difuso da constitucionalidade e a coisa julgada *erga omnes* das ações coletivas. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, v. 51, n. 307, p. 7-12, maio 2003.
- . *O processo em evolução*. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
- . *O processo em sua unidade*. São Paulo: Saraiva, 1978.
- . *Processo constitucional em marcha*. São Paulo: Max Limonad, 1985.
- (Coord.). *A tutela dos interesses difusos*. São Paulo: Max Limonad, 1984 (Série Estudos jurídicos, n. 1).
- ; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). *Participação e processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
- ; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães. *As nulidades no processo penal*. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
- GYLFASON, Thorvaldur. *From collapse to Constitution: The case of Iceland*. In: PAGANETTO, Luigi (Ed.). *Public Debt, Global Governance and Economic Dynamism*, Springer Milan, 2013, p. 379-417.
- HÄBERLE, Peter. *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição — contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição*. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1997.
- HART, Hebert L. A. The ascription of responsibility and rights. *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, v. 49 (1948-1949), p. 171-194.
- HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1997, 2002 (reimpr.).
- HORBACH, Carlos Bastide. A nova roupa do direito constitucional: neoconstitucionalismo, pós-positivismo e outros modismos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 96, n. 859, p. 81-91, maio 2007.
- HORTA, Raul Machado. *Direito constitucional*. 5. ed. rev. e atual. por Juliana Campos Horta. Belo Horizonte: Del Rey, 2010 (4. ed., 2003).
- ISERN, Luiz Francisco. *Controle de constitucionalidade por meio do veto municipal*. São

- Paulo: Método, 2002.
- IVO, Gabriel. *Constituição estadual: competência para elaboração da Constituição do Estado-membro*. São Paulo: Max Limonad, 1997.
- JESUS, Damásio E. de. *Código de processo penal anotado*. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1996.
- . *Código penal anotado*. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1996.
- . Conceito de idoso na legislação penal brasileira. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, mar. 2004. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/artigos/art_183.htm>.
- . *Direito penal*. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1.
- . *Foro por prerrogativa de função*. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, fev. 2003. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- . *Imunidade parlamentar processual — nova trapalhada legislativa*. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, fev. 2002. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- . Ação penal sem crime. *Phoenix — Órgão Informativo do Complexo Jurídico Damásio de Jesus*, n. 38, dez. 2000.
- . Só os pobres vão sujar os dedos. *Phoenix — Órgão Informativo do Complexo Jurídico Damásio de Jesus*, n. 4, fev. 2001.
- KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. Coimbra: Arménio Amado Ed., 1984 (Coleção Stvdivm; Temas filosóficos, jurídicos e sociais).
- KISS, Alexandre. *Droit international de l'environnement: études internationales*. Paris: A. Pedone, 1989, n. 3.
- LARENZ, Karl. *Derecho justo: fundamentos de ética jurídica*. Traducción y presentación de Luis Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 1985 (Monografías Civitas).
- ; Lamego, Jose (Trad.); Freitas, Ana (rev.). *Metodologia da ciência do direito*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.
- LEAL, Roger Stiefelmann. *O efeito vinculante na jurisdição constitucional*. São Paulo, 2004. Tese apresentada para a obtenção do título de Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo.
- LEITE, Eduardo de Oliveira. *A monografia jurídica*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
- LENZA, Pedro. A arguição de descumprimento de preceito fundamental sob a perspectiva do STF. In: TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius (Coord.). *Aspectos atuais do*

- controle de constitucionalidade no Brasil: recurso extraordinário e a arguição de descumprimento de preceito fundamental*. São Paulo: Forense, 2003.
- . A importância das escolas de aperfeiçoamento vinculadas às carreiras jurídicas — a Escola Superior de Advocacia. *Jornal OAB/Pinheiros*, São Paulo, ano IV, n. 12, out. 2001.
- . As garantias processuais dos tratados internacionais sobre direitos fundamentais. In: ROCHA, Júlio César de Sá; MISI, Márcia Costa (Org.). *O direito e os desafios da contemporaneidade*. São Paulo: LTr, 1999.
- . Breves comentários sobre a Resolução n. 1/02-CN, que dispõe sobre a tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional em consonância com a EC n. 32/01. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, jun. 2002. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- . Breves comentários sobre as medidas provisórias de acordo com a Emenda Constitucional n. 32, de 11.09.2001. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, dez. 2001. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- . *Coisa julgada erga omnes*: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante, 2006 (Tese de Doutorado — USP).
- . Competência na ação civil pública: dano de âmbito local, regional e nacional — art. 93 do CDC. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 30, n. 129, p. 272-284, nov. 2005.
- . E por que não a Justiça? *Revista Tributária e de Finanças Públicas* (Academia Brasileira de Direito Tributário), São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 41, nov./dez. 2001.
- . Efectividad del proceso colectivo: el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica y el derecho brasileño. In: GIDI, Antonio; MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer (Coord.). *La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos hacia un Código Modelo para Iberoamérica*. México: Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal/Porrúa, 2003. p. 157-173.
- . *Teoria geral da ação civil pública*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
- . Trabalho forense: “modelo de ação rescisória de acórdão do Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto o valor da alíquota da contribuição devida para o Finsocial, envolvendo empresa prestadora de serviço”. *Revista Tributária e de Finanças Públicas* (Academia Brasileira de Direito Tributário), São Paulo, n. 43, mar./abr. 2002.
- LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. *Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
- LLORENTE, Francisco. *Derechos fundamentales y principios constitucionales*. Barcelona:

- Ariel, 1995.
- LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Coord.). *Leituras complementares de direito civil: o direito civil-constitucional em concreto*. Salvador: Jus Podivm, 2007.
- LOEWENSTEIN, Karl. *Teoría de la Constitución*. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1970.
- MACEDO, Dimas. *O discurso do poder constituinte: uma abordagem crítica*. Fortaleza: Casa de José de Alencar, 1997.
- MACHADO, Hugo de Brito. Efeitos da medida provisória rejeitada. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 83, n. 700, p. 46-47, fev. 1994.
- MACHADO, Paulo Affonso Leme. *Direito ambiental brasileiro*. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1996.
- MAMARI FILHO, Luís Sérgio Soares. *A comunidade aberta de intérpretes da Constituição: o amicus curiae como estratégia de democratização da busca do significado das normas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Ação civil pública, em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e dos consumidores (Lei n. 7.347/85 e legislação complementar)*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
- . *Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente*. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001 (Coleção Controle Jurisdicional dos Atos do Estado).
- . *Divergência jurisprudencial e súmula vinculante*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- . *Interesses difusos: conceito e legitimação para agir*. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
- MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. *Padrões de racionalidade na sistematização de normas*. São Paulo, 2004. 219 p. Tese de Doutorado, FADUSP, FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, orient.
- MARSHALL, John; 1755-1835. *Decisões constituintes de Marshall*. Reimpressão fac-similar. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. (Arquivos do Ministério da Justiça.) Trad. Américo Lobo; Apresentação de Nelson A. Jobim; Introdução de Josaphat Marinho.
- MARSHALL, Thomas Humphrey. *Cidadania, classe social e status*. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
- MARTÍN MATEO, Ramón. *Derecho ambiental*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración

- Local, 1977.
- MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. *Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10.11.99*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- ; ——— (Coord.). *Ação declaratória de constitucionalidade*. São Paulo: Saraiva, 1994; 2. tir., 1995.
- ; ———; NASCIMENTO, Carlos Valder do. *Tratado de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2010. v. I e II.
- MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- MAZZILLI, Hugo Nigro. A prática de “atividade jurídica” nos concursos. In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lara (Coord.). *Reforma do Judiciário: Emenda Constitucional n. 45/2004*. São Paulo: Método, 2005.
- . *Introdução ao Ministério Público*. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.
- . *O foro por prerrogativa de função e a Lei n. 10.628/02*. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, jan. 2003. Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- . *Regime jurídico do Ministério Público*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
- MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. *Curso de direito internacional público*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
- . *Direitos humanos & relações internacionais*. Campinas: Agá Juris, 2000.
- . *Tratados internacionais*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.
- MCGOLDRICK, Dominic. Sustainable development and human rights and integrated conception. *International and Comparative Law Quarterly*, London, v. 45, n. 4, p. 796-818, oct. 1996.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 18. ed. atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1993.
- . *Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”*. 19. ed. atual. por Arnaldo Wald. São Paulo: Malheiros, 1998.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Conteúdo jurídico do princípio da igualdade*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
- . *Curso de direito administrativo*. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1994.
- . *Discrecionariedade e controle jurisdicional*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
- MELLO FILHO, José Celso de. *Algumas notas informativas (e curiosas) sobre o Supremo Tribunal (Império e República)*: Texto elaborado pelo Ministro Celso de Mello com o apoio

- técnico da Secretaria de Documentação do STF, sob a direção de Maria Cristina Rodrigues Silvestre. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br/institucional/notas>>.
- . *Constituição Federal anotada*. São Paulo: Saraiva, 1984.
- MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. *Princípios gerais de direito administrativo*: introdução. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. v. I.
- MELO, Mônica de. Direitos políticos de participação e controle popular no regime republicano presidencialista brasileiro: o plebiscito e o referendun. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, dez. 1993.
- . *Plebiscito, referendo e iniciativa popular*: mecanismos constitucionais de participação popular. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2001.
- MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (I) (§ 1.º do art. 102 da Constituição Federal). *Revista Jurídica Virtual*, n. 7, dez. 1999.
- . *Controle de constitucionalidade*: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990.
- . *Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade*: estudos de direito constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004.
- . *Jurisdição constitucional*: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- . *Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2004.
- . O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso clássico de mutação constitucional. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 41, n. 162, p. 149-168, abr./jun. 2004.
- . Tribunal Constitucional alemão. O apelo ao legislador — “appellentscheidung” — na prática da corte constitucional alemã. *Revista de Direito Público*, São Paulo, v. 25, n. 99, p. 32-53, jul./set. 1991.
- ; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- ; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2007 (5. ed., 2010).
- MENEZES, Paulo Lucena de. *A ação afirmativa (“affirmative action”) no direito norte-americano*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- MENDONÇA, Andrey Borges; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. *Eficácia dos direitos*

- fundamentais nas relações privadas: leituras complementares de constitucional — direitos fundamentais*. Org. Marcelo Novelino Camargo. Salvador: Jus Podivm, 2006.
- MILARÉ, Édis. *Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
- . Tutela jurisdicional do ambiente. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 81, n. 676, p. 48-59, fev. 1992.
- MIRABETE, Julio Fabbrini. *Processo penal*. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 1994.
- MIRANDA, Jorge. *Manual de direito constitucional*. 2. ed. Coimbra: [s.n.], 1987. t. 2.
- MONTE ALEGRE, José Sérgio. Ação popular não é direito político. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, n. 189, p. 123-38, jul./set. 1992.
- MONTORO, André Franco. *Introdução à ciência do direito*. 20. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.
- MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional*. São Paulo: Atlas, 2002.
- . *Direito constitucional*. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 1999.
- MORAES, Guilherme Peña de. *Curso de direito constitucional*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- MORAES, Humberto Peña de; SILVA, José Fontenelle T. da. *Assistência judiciária: sua gênese, sua história e a função protetiva do Estado*. 2. ed. Rio de Janeiro: [s.n.], 1984.
- MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. *Direito, Estado e Sociedade*, Rio de Janeiro, n. 1, p. 59-73, jul./dez. 1991.
- MORAIS, José Luis Bolzan de. *Do interesse social aos interesses transindividuais: o Estado e o direito na ordem contemporânea*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.
- MOREIRA, Eduardo Ribeiro. *Neoconstitucionalismo: a invasão da Constituição*. São Paulo: Método, 2008 (Coleção Professor Gilmar Mendes. v. 7).
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Interferência entre Poderes do Estado — fricções entre o Executivo e o Legislativo na Constituição de 1988. *Revista de Informação Legislativa Brasileira*, ano 26, n. 103, jul./set. 1989.
- . *Mutações do direito administrativo*. 2. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- MOTA, Leda Pereira; SPITZCOVSKY, Celso. *Curso de direito constitucional*. 4. ed. atual. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999.
- MUSCARI, Marco Antônio Botto. *Súmula vinculante*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. Dissertação de Mestrado — FADUSP.

- NALINI, José Renato. *Recrutamento e preparo de juízes na Constituição do Brasil de 1988*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
- NASCIMENTO, Luiz Sales do. *Direito constitucional comparado: pressupostos teóricos e princípios gerais*. São Paulo: Verbatim, 2011.
- NERY JUNIOR, Nelson. *Princípios do processo civil na constituição federal*. 4. ed. rev. e aum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997 (Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebmann, v. 21).
- ; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil comentado*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
- ; ———. *Leis civis comentadas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. Atualizadas até 20.07.2006.
- ; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). *Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005 (Textos de vários autores).
- NEVES, Marcelo. *A constitucionalização simbólica*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007 (Coleção Justiça e Direito).
- . *Transconstitucionalismo*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
- NOGUEIRA, Gustavo Santana. *Do amicus curiae*. *Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, n. 63, p. 13-28. abr./jun. 2005.
- NUNES, José de Castro. *Teoria e prática do Poder Judiciário*. Rio de Janeiro: Forense, 1943.
- OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. *Curso de processo penal*. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- OLIVEIRA JR., José Alcebiades de; MORATO, José Rubens Leite (Org.). *Cidadania coletiva*. Florianópolis: Paralelo 27, 1996.
- ORTEGA Y GASSET, José. *A rebelião das massas*. Trad. Marylene Pinto Michel. Rev. Maria Estela Heider Cavalheiro. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
- PACHECO, José da Silva. *Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas*. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
- PALU, Osvaldo Luiz. *Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos*. 2. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com as Leis 9.868 e 9.882/99. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. *Controle de constitucionalidade*. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006.
- ; ———. *Direito constitucional descomplicado*. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:

- Forense; São Paulo: Método, 2010.
- ; ———. *Processo legislativo*. Niterói: Impetus, 2005.
- ; ———; MAIA, Juliana (Org.). *Aulas de direito constitucional*. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006.
- PAZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo: um modelo constitucional ou uma concepção da Constituição? *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, São Paulo, v. 1, n. 7, p. 231-53, jan./jun. 2006.
- PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. *Interpretação constitucional e direitos fundamentais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- PIÇARRA, Nuno. *A separação de poderes como doutrina e princípio constitucional: um contributo para o estudo das suas origens e evolução*. Coimbra: Coimbra Ed., 1989.
- PIMENTA BUENO, José Antônio. *Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Serviço de Documentação, 1958. v. 16.
- PINTO, Élide Graziane; SARLET, Ingo Wolfgang. Regime previsto na EC 86/2015 deve ser piso e não o teto de gasto em saúde. *Revista Consultor Jurídico*, 24.03.2015.
- PIOVESAN, Flávia Cristina. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. São Paulo: Max Limonad, 1996.
- . *Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários à Constituição de 1946*. Rio de Janeiro: Henrique Cahen, Editor. v. I (arts. 1-36).
- POPP, Carlyle. A retroatividade das normas constitucionais e os efeitos da constituição federal sobre os direitos adquiridos. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 29, n. 113, jan./mar. 1992.
- PORTO, Noemia A. Garcia. Novas perspectivas do controle da omissão inconstitucional no direito brasileiro. In: TAVARES, André Ramos; FERREIRA, Olavo A. V. Alves; LENZA, Pedro (Coord.). *Constituição Federal: 15 anos — mutação e evolução — comentários e perspectivas*. São Paulo: Método, 2003.
- . *Temas relevantes de direito constitucional: poder constituinte*. Brasília: Fortium, 2005.
- PRADO, Luiz Regis. *Crimes contra o ambiente: anotações à Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 — doutrina, jurisprudência, legislação*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

- . *Direito penal ambiental: problemas fundamentais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
- RAMOS, Dirceo Torrecillas. *O federalismo assimétrico*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
- RAMOS, Elival da Silva. *A ação popular como instrumento de participação política*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.
- . *A inconstitucionalidade das leis: vício e sanção*. São Paulo: Saraiva, 1994 (originalmente apresentada como tese de doutorado à FADUSP/1992).
- . *Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- RANGEL JUNIOR, Hamilton. *Princípio da moralidade institucional: conceito, aplicabilidade e controle na Constituição de 1988*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.
- REZEK, José Francisco. *Direito internacional público: curso elementar*. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.
- ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Sobre a súmula vinculante. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 34, n. 133, p. 51-64, jan./mar. 1997.
- RODRIGUES, Maurício Andreiulo. *Poder constituinte supranacional: esse novo personagem*. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2000.
- ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. *Forças policiais no sistema constitucional*, página “direito militar”. Disponível em: <<http://militar.com.br>>. 2003, p. 1-4.
- ROTHENBURG, Walter Claudius. *Princípios constitucionais*. 2. tir. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2003.
- . *Direito constitucional*. São Paulo: Verbatim, 2010.
- ROTONDANO, José Edivaldo Rocha. Ministério Público entende que casamento em centro espírita pode ter efeitos civis. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 914, 3 jan. 2006. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=666>>. Acesso em: 26 jan. 2008.
- SAMPAIO, Francisco José Marques. O dano material e a responsabilidade. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 185. p. 41-62. jul./set. 1991.
- SAMPAIO, José Adércio Leite. *A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
- SANTOS, Aricê Moacyr Amaral. *O estado de emergência*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989 (originalmente defendida como dissertação de mestrado na PUCSP).
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *La reinención del Estado y el Estado plurinacional*. Santa Cruz de la Sierra: Bolívia, 2007. (Alianza Interinstitucional CENDA/CEJIS/CEBID).
- SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). *A Constituição concretizada: construindo pontes com o público*

- e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- . A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. *Arquivos de Direitos Humanos*, Rio de Janeiro, v. 6, p. 99-145, 2006.
- . *A eficácia dos direitos fundamentais*. 7. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- . A reforma do Judiciário e os tratados internacionais de direitos humanos: observações sobre o § 3.º do art. 5.º da Constituição. *Interesse Público*, Porto Alegre, v. 8, n. 37, p. 49-64, 2006.
- ; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Curso de direito constitucional*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
- SARMENTO, Daniel (Org.). A normatividade da Constituição e a constitucionalização do direito privado. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, p. 272-297, 2003.
- . *A ponderação de interesses na Constituição Federal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
- . A trajetória da dicotomia público/privado. *Revista Trimestral de Direito Civil*, São Paulo, v. 6, n. 22, p. 239-257, abr./jun. 2005.
- . Apontamentos sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 224, p. 95-116, abr./jun. 2001.
- . Comentário ao art. 5.º, IV. In: MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.
- . Constituição e globalização: a crise dos paradigmas do direito constitucional. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 215, p. 19-34, jan./mar. 1999.
- . Direito adquirido, emenda constitucional, democracia e a reforma da previdência. *Arquivos de Direitos Humanos*, Rio de Janeiro, v. 6, p. 3-36, 2006.
- . *Direitos fundamentais e relações privadas*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- . Direitos sociais e globalização: limites ético-jurídicos ao realinhamento constitucional. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 223, p. 153-168, jan./mar. 2001.
- . Eficácia temporal do controle de constitucionalidade das leis. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 212, p. 27-40, abr./jun. 1998.
- . *Livres e iguais: estudos de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- . *O controle de constitucionalidade e a Lei n. 9.868/99*. Rio de Janeiro: Lumen Juris,

2001.

SCHIER, Paulo Ricardo. *Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática jurídica*. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1999.

SEVERINO, Antônio Joaquim. *Metodologia do trabalho científico*. 20. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 1996.

SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. *Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada: doutrina e jurisprudência dos 27 Estados da federação*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

SILVA, José Afonso da. *Ação popular constitucional: doutrina e processo*. 2. ed. rev., ampl. e aum. São Paulo: Malheiros, 2007.

———. *Ação popular constitucional: doutrina e processo*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968.

———. *Aplicabilidade das normas constitucionais*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998.

———. *Comentário contextual à Constituição*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2007 (8. ed., 2012).

———. *Curso de direito constitucional positivo*. 36. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 2013.

———. *Curso de direito constitucional positivo*. 35. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 66, de 21.12.2011. São Paulo: Malheiros, 2012.

———. *Direito ambiental constitucional*. 2. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1995.

———. *Direito urbanístico brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

———. *Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963.

———. *Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a Constituição*. São Paulo: Malheiros, 2000.

———. *Processo constitucional de formação das leis*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

SILVA, Luis Virgílio Afonso da (Org.). *Interpretação constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2005.

———. *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*. São Paulo: Malheiros, 2005 (originalmente apresentada como tese de livre-docência à Faculdade de Direito da USP).

———. Direitos fundamentais e relações entre particulares. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 173-180, maio 2005.

———. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, Luis Virgílio Afonso da (Org.). *Interpretação constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 115-143.

- . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. *RDE, Revista de Direito do Estado Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 23-51, out./dez. 2006.
- . *O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais*. São Paulo, 2005. Tese — Professor Titular da FADUSP.
- . O proporcional e o razoável. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 91, n. 798, p. 23-50, abr. 2002.
- . Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. *Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais*, Belo Horizonte, n. 1, p. 607-630, jan./jun. 2003.
- . *Sistemas eleitorais: tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 1999 (originalmente apresentada como dissertação de mestrado à Faculdade de Direito da USP, 1998).
- SIQUEIRA, Luiz Eduardo Alves de. *Estatuto do idoso de A a Z*. Aparecida: Ideias & Letras, 2004.
- SOARES, Guido Fernando Silva. *As responsabilidades no direito internacional do meio ambiente*. São Paulo, 1995. Tese — Titular da Faculdade de Direito da USP.
- SOARES, Rosinethe Monteiro. A prática da elaboração legislativa. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 29, n. 114, abr./jun. 1992.
- SOMBRA, Thiago Luís Santos. *A eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas: a identificação do contrato como ponto de encontro dos direitos fundamentais*. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2004.
- ; FRANCIULLI NETTO, Domingos. O direito à imagem em locais públicos. In: MARTINS, Ives Gandra; PEREIRA JÚNIOR, Antônio Jorge (Org.). *Direito à privacidade*. São Paulo: Ideias e Letras/Centro de Extensão Universitária, 2005.
- SORMANI, Alexandre; SANTANDER, Nelson Luis. *Súmula vinculante: um estudo à luz da Emenda Constitucional 45, de 30.12.2004*. Curitiba: Juruá, 2006.
- SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao art. 144. In: MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.
- ; SARMENTO, Daniel. *Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho*. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
- STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito*. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

- . *Jurisdição constitucional e hermenêutica*. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- . A atualidade do debate da crise paradigmática do direito e a resistência positivista ao neoconstitucionalismo. *Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos*, Bauru, v. 40, n. 45, p. 257-290, jan./jun. 2006.
- . *Súmulas no direito brasileiro — eficácia, poder e função: a ilegitimidade constitucional do efeito vinculante*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- . Por que é inconstitucional “repristinar” a separação judicial no Brasil. *Revista Consultor Jurídico — CONJUR*, 18.11.2014 — 8h. Acesso em: 18.05.2015.
- . *Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- SUNDFELD, Carlos Ari. *Fundamentos do direito público*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
- TARTUCE, Fernanda. *Processo civil aplicado ao direito de família*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012.
- TARTUCE, Flávio. *O novo CPC e o direito civil: impactos, diálogos e interações*. São Paulo: Método, 2015.
- TARTUCE, Flávio; OPROMOLLA, Márcio Araújo. Direito civil e Constituição. In: TAVARES, André Ramos; FERREIRA, Olavo A. V. Alves; LENZA, Pedro (Coord.). *Constituição Federal: 15 anos — mutação e evolução — comentários e perspectivas*. São Paulo: Método, 2003.
- TARUFFO, Michele. *La motivazione della sentenza civile*. Padova: CEDAM, 1975. xi (Série Pubblicazioni della Università di Pavia: Studi nelle scienze giuridiche e sociali; nuova ser.; v. 14).
- TAVARES, André Ramos. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2002.
- . *Curso de direito constitucional*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- . *Nova lei da súmula vinculante: estudos e comentários à Lei 11.417, de 19.12.2006*. São Paulo: Método, 2007.
- . *Tratado da arguição de descumprimento de preceito fundamental: Lei n. 9.868/99 e Lei n. 9.882/99*. São Paulo: Saraiva, 2001.
- . *Tribunal e jurisdição constitucional*. São Paulo: Celso Bastos, Editor/Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1998.
- ; FERREIRA, Olavo A. V. Alves; LENZA, Pedro (Coord.). *Constituição Federal: 15 anos — mutação e evolução — comentários e perspectivas*. São Paulo: Método, 2003.
- ; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (Coord.). *Reforma do Judiciário:*

- analisada e comentada — Emenda Constitucional 45/2004. São Paulo: Método, 2005 (inclui textos complementares à Reforma do Judiciário e Quadro comparativo da Reforma do Judiciário).
- ; ROTHENBURG, Walter Claudius (Org.). *Arguição de descumprimento de preceito fundamental*: análises à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001.
- TEIXEIRA, J. H. Meirelles. *Curso de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Forense, 1991.
- TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). *As garantias do cidadão na justiça*. [colaboradores: Ada Pellegrini Grinover et al.], 1993.
- TEMER, Michel. *Elementos de direito constitucional*. 14. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998.
- TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. t. 1.
- TUCCI, José Rogério Cruz e. “*Class action*” e *mandado de segurança coletivo*: diversificações conceituais. São Paulo: Saraiva, 1990.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Coordenadoria Geral de Bibliotecas, Editora UNESP. *Normas para publicações da UNESP*. São Paulo: Ed. UNESP, 1994. 4 v., v. 2 — Referências Bibliográficas.
- . Coordenadoria Geral de Bibliotecas, Editora UNESP. *Normas para publicações da UNESP*. São Paulo: Ed. UNESP, 1994. 4 v., v. 4 — Parte I: Dissertações e Teses.
- VARELLA, Marcelo Dias. *Direito internacional público*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- VARGAS, Idón Moisés Chivi. Os caminhos da descolonização na América Latina: os povos indígenas e o igualitarismo jurisdicional na Bolívia. In: VERDUM, Ricardo (Org.). *Povos indígenas*: Constituições e reformas políticas na América Latina. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009. p. 151-166.
- VASCONCELLOS, Fernando Andreoni. *Hermenêutica jurídica e derrotabilidade*. Curitiba: Juruá, 2010.
- VELLOSO, Carlos Mario da Silva. Intervenção da União nos Estados e Municípios — a autonomia dos entes federados — inobservância da ordem cronológica. *Boletim de Direito Administrativo*, São Paulo, v. 13, n. 5, 1997, p. 309-317.
- VELOSO, Zeno. *Controle jurisdicional de constitucionalidade*: atualizado conforme as Leis 9.868, de 10.11.1999 e 9.882, de 03.12.1999. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
- VERDUM, Ricardo (Org.). *Povos indígenas*: Constituições e reformas políticas na América

- Latina. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009.
- VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. *Revista Direito GV*, São Paulo, n. 8, p. 441-464, jul./dez. 2008.
- . *Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência política*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
- VIGLIAR, José Marcelo Menezes. *Tutela jurisdicional coletiva*. São Paulo: Atlas, 1998.
- WATANABE, Kazuo et al. *Juizado especial de pequenas causas: Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985.
- . Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. *Participação e processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
- . *Controle jurisdicional: princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional no sistema jurídico brasileiro e mandado de segurança contra atos judiciais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.
- WILHELMI, Marco Aparicio. *Possibilidades e limites do constitucionalismo pluralista: direitos e sujeitos na Constituição equatoriana de 2008*. In: VERDUM, Ricardo (Org.). *Povos indígenas: Constituições e reformas políticas na América Latina*. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009. p. 135-150.
- YARSHELL, Flávio Luiz. *Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório*. São Paulo: Malheiros, 2005.
- . *Tutela jurisdicional*. São Paulo: Atlas, 1998.
- YRIGOYEN FAJARDO, Raquel Z. Aos 20 anos da Convenção 169 da OIT: balanço e desafios da implementação dos direitos dos povos indígenas na América Latina. In: VERDUM, Ricardo (Org.). *Povos indígenas: Constituições e reformas políticas na América Latina*. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009. p. 11-62.
- . El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización. In: GARAVITO, César Rodríguez. *El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. p. 139-159.
- . Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino. In: BERRAONDO, Mikel (Coord.). *Pueblos indígenas y derechos humanos*. Bilbao: Universidad de Deusto, 2006. p. 537-567.
- ZAGREBELSKY Gustavo. *El derecho dúctil: ley, derechos, justicia*. Traducción de Marina Gascón. 7. ed. Madrid: Trotta, 2007 (Colección Estructuras y Procesos — Serie Derecho).
- . *Il diritto mite*. Legge, diritti, giustizia. Torino: Einaudi, 1992.

ZAMUDIO, Héctor Fix; ESPINOZA Alejandro Ríos; ALCALÁ-ZAMORA, Niceto. *Tres estudios sobre el mandado de seguridad brasileño*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1963 (Publicaciones del Instituto de Derecho Comparado. Serie D: Cuadernos de Derecho Comparado).

ZAVASCKI, Teori Albino. *Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

ZIMMERMANN, Augusto. *Curso de direito constitucional*. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002 (4. ed., 2006).

———. *Teoria geral do federalismo democrático*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

■ SITES DA INTERNET

- <http://143.107.2.22/w2sdi.htm>
- <http://www.aasp.org.br>
- <http://www.camara.leg.br>
- <http://www.cl.df.gov.br>
- <http://www.cnj.jus.br>
- <http://www.cnmp.mp.br>
- <http://www.damasio.com.br>
- <http://www.direitocriminal.com.br>
- <http://www.direitopublico.com.br>
- <http://www.fd.unl.pt/Jurist/Investig/dconst.htm>
- <http://www.ibccrim.com.br>
- <http://www.icc-cpi.int>
- <http://www.in.gov.br>
- <http://www.mercosul.gov.br>
- <http://www.militar.com.br>
- <http://www.mp.sp.gov.br>
- <http://www.mre.gov.br>
- <http://www.noronha.pe.gov.br>
- <http://www.oabsp.org.br/>

- <http://www.oprocesso.com>
- <http://www.pge.sp.gov.br>
- <http://www.pgr.mpf.gov.br>
- <http://www.planalto.gov.br>
- <http://www.prossiga.br/prossigabrasil>
- <http://www.receita.fazenda.gov.br>
- <http://www.saraivajur.com.br>
- <http://www.senado.gov.br>
- <http://www.stf.jus.br>
- <http://www.stj.jus.br>
- <http://www.stm.jus.br>
- <http://www.tcu.gov.br>
- <http://www.tjdft.jus.br>
- <http://www.tjmmg.jus.br>
- <http://www.tjmso.jus.br>
- <http://www.tjso.jus.br>
- <http://www.tse.jus.br>
- <http://www.tst.jus.br>

- 1 Texto escrito para a 15.^a ed. (02.02.2011). A Manu tinha 8 meses de idade. Hoje está com 5 anos...**Toda a emoção daquele momento renova-se a cada dia.** A dualidade, as dificuldades são as mesmas (ou parecem aumentar). A certeza de que tenho uma missão na vida, qual seja, ajudar na realização de sonhos, fica mais forte a cada dia e no contato com os *guerreiros do Brasil*. Por isso continuo, firme e forte, tentando equilibrar essas forças que parecem antagônicas, mas que, no fundo, se somam e contribuem para o sucesso de todos!
- 2 Confira os textos seguintes: “Uma nova homenagem especial” e “Mais uma nova homenagem especial”.
- 3 Texto escrito para a 18.^a ed. (20.02.2014). O Max tinha 8 meses de idade (curiosamente, a mesma idade da Manu quando lançamos a 15.^a ed., já que ambos são de maio e com diferença de 3 anos). Hoje, o Macão está com 2 anos. Também devo reconhecer que **toda emoção daquele momento renova-se, ou potencializa-se, a cada dia.** Quando esse texto foi escrito, o Tommy ainda não havia nascido. Sem dúvida, fato marcante para *mais uma nova homenagem especial*...

- 1 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 36.
- 2 Nesse sentido, cf. Maria Celina Bodin de Moraes, A caminho de um direito civil constitucional, *Direito, Estado e Sociedade*, n. 1, p. 59-73, jul./dez. 1991, e Julio César Finger, Constituição e direito privado: algumas notas sobre a chamada constitucionalização do direito civil, in Ingo W. Sarlet (org.), *A Constituição concretizada*, p. 86-89.
- 3 Novamente, alertamos que esse tema sobre as **gerações** ou **dimensões de direitos** será retomado no capítulo sobre os direitos fundamentais, *item 14.2*.
- 4 Sobre essa perspectiva do **Direito civil-constitucional**, cf. Gustavo Tepedino, *Temas de direito civil*, 4. ed., t. 1, passim. Cf., ainda, Paulo Luiz Netto Lôbo, Constitucionalização do direito civil, in Cristiano Chaves de Farias (coord.), *Leituras complementares de direito civil*, p. 21-36; Maria Celina Bodin de Moraes, A caminho de um direito constitucional positivo, passim; Julio César Finger, Constituição e direito privado, p. 85-101; Eugênio Facchini Neto, Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado, in Ingo W. Sarlet, *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*, p. 13-62; Luiz Edson Fachin, *Direito de família: elementos críticos à luz do novo Código Civil*, passim; Flávio Tartuce e Márcio Araújo Opromolla, Direito civil e Constituição, in *Constituição Federal: 15 anos...*, p. 367-399.
- 5 Conforme anota Julio César Finger, “... os princípios constitucionais, entre eles o da **dignidade da pessoa humana** (CF, art. 1.º, inciso III), que é sempre citado como um **princípio-matriz de todos os direitos fundamentais**, colocam a pessoa em um patamar diferenciado do que se encontrava no Estado Liberal. O direito civil, de modo especial, ao expressar tal ordem de valores, tinha por norte a regulamentação da vida privada unicamente do ponto de vista do patrimônio do indivíduo. Os princípios constitucionais, em vez de apregoar tal conformação, têm por meta orientar a ordem jurídica para a **realização de valores da pessoa humana como titular de interesses existenciais**, para além dos meramente patrimoniais. O direito civil, de um direito-proprietário, passa a ser visto como uma regulação de interesses do homem que convive em sociedade, que deve ter um lugar apto a propiciar o seu desenvolvimento com dignidade. Fala-se, portanto, em uma **despatrimonialização do direito civil**, como consequência da sua constitucionalização” (Constituição e direito privado, p. 94-95).
- 6 Esse tema será retomado no *item 6.1* do capítulo sobre o “controle de constitucionalidade”.

- 7 Ao estudarmos o tema do controle de constitucionalidade, como desmembramento dessa perspectiva, analisaremos a temática da **interpretação conforme a Constituição** (cf. *item 6.7.1.17.2*).
- 8 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 51.
- 9 Kildare Gonçalves Carvalho, *Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição*. Direito constitucional positivo, 12. ed., p. 211.
- 10 André Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 1.
- 11 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 52.
- 12 Karl Loewenstein, *Teoría de la Constitución*, p. 154.
- 13 Karl Loewenstein, *Teoría de la Constitución*, p. 155.
- 14 Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, tanto a **Magna Carta de 1215** como o **Petition of Rights de 1628** são exemplos dos denominados **pactos** firmados durante a história constitucional inglesa, ou seja, “... convenções entre o monarca e os súditos concernentes ao modo de governo e às garantias dos direitos individuais. Seu fundamento é o *acordo de vontades* (ainda que os reis disfarcem sua transigência com a roupagem da outorga de direitos) ...” (*Curso de direito constitucional*, 32. ed., p. 4-5).
- 15 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, p. 5.
- 16 Kildare Gonçalves Carvalho, *Direito constitucional*, 15. ed., p. 247.
- 17 Uadi Lammêgo Bulos, *Constituição Federal anotada*, 5. ed., p. 16-18.
- 18 André Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 8. ed., p. 37.
- 19 André Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 8. ed., p. 38, e, falando de um **dirigismo comunitário**, Bulos, *Constituição Federal anotada*, 5. ed., p. 19.
- 20 Ingo W. Sarlet, *A eficácia dos direitos fundamentais*, 7. ed., p. 58. Este tema sobre as **dimensões de direitos fundamentais** será **esquematizado** no *item 14.2* deste estudo.
- 21 Sobre o **constitucionalismo fraternal**, cf. interessantes julgados do STF: **ADI 3.510** (pesquisas com células-tronco embrionárias), **Pet 3.388** (demarcação Raposa Serra do Sol), **HC 106.212** (Lei Maria da Penha) e **ADPF 132** (união homoafetiva).
- 22 Cf. José Roberto Dromi, La reforma constitucional: el constitucionalismo del “por-venir”, in Eduardo García de Enterría e Manuel Clavero Arévalo (coord.), *El derecho público de*

pinales de siglo, passim. Cf., ainda, Celso Ribeiro Bastos e André Ramos Tavares, *As tendências do direito público no limiar de um novo milênio*, p. 54 e s.; Uadi Lammêgo Bulos, *Constituição Federal anotada*, p. 22; e Kildare Gonçalves Carvalho, *Direito constitucional*, p. 220-221.

23 No tocante aos concursos públicos, o tema aparece, dentre outros, no Edital do *IV Concurso Público de Provas e Títulos ao Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo* (2010).

24 Para um aprofundamento do estudo, confira: Luis Roberto Barroso, *Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)*, *RF* 384/71-104; Écio Oto Ramos Duarte e Susanna Pozzolo, *Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da Constituição*, passim (com posfácio de Lenio Luiz Streck de indispensável e interessante leitura); Dimitri Dimoulis e Écio Oto Ramos Duarte (coord.), *Teoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?*, passim; Eduardo Ribeiro Moreira, *Neoconstitucionalismo: a invasão da Constituição*, passim; Dimitri

Dimoulis, Uma visão crítica do neoconstitucionalismo, in George Salomão Leite e Glauco Salomão Leite (coord.), *Constituição e efetividade constitucional*; Ana Paula de Barcellos, *Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas*, *RDA* 240/83-103; Lenio Luiz Streck, A atualidade do debate da crise paradigmática do direito e a resistência positivista ao neoconstitucionalismo, *RIPE* 45/257-90; Carlos Bastide Horbach, A nova roupa do direito constitucional: neoconstitucionalismo, pós-positivismo e outros modismos, *RT* 859/81-91; Susanna Pazzolo, Neoconstitucionalismo: um modelo constitucional ou uma concepção da Constituição?, *RBDC* 7/231-53; Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo(s), passim. Conferir interessante visão crítica de Humberto Ávila, “Neoconstitucionalismo”: entre a “ciência do direito” e o “direito da ciência”, passim.

25 Kildare Gonçalves Carvalho, *Direito constitucional*, 14. ed., p. 239.

26 Walber de Moura Agra, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 31.

27 Walber de Moura Agra, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 31.

28 Ana Paula de Barcellos, *Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas*, p. 4 (<http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto853.pdf>).

29 Ana Paula de Barcellos, op. cit., p. 4.

- 30 Ana Paula de Barcellos, op. cit., p. 7-8.
- 31 *Curso de direito constitucional*, p. 35 (grifamos).
- 32 Luis Roberto Barroso, *Neoconstitucionalismo: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil*,
p. 5 (<http://www.conjur.com.br/static/text/43852>).
- 33 Todas as citações e a exposição seguem o trabalho de Luis Roberto Barroso, op. cit., passim.
- 34 Em relação à Constituição do Equador, cf.: Agustín Grijalva, *O Estado plurinacional e intercultural na Constituição equatoriana de 2008*, passim, e Marco Aparicio Wilhelmi, *Possibilidades e limites do constitucionalismo pluralista: direitos e sujeitos na Constituição equatoriana de 2008*, passim.
- 35 Para mais discussões sobre a Constituição da Bolívia, cf. Idón Moisés Chivi Vargas, *Os caminhos da descolonização na América Latina: os povos indígenas e o igualitarismo jurisdicional na Bolívia*, passim, e Fernando Garcés V., *Os esforços de construção descolonizada de um Estado plurinacional na Bolívia e os riscos de vestir o mesmo cavaleiro com um novo paletó*, passim.
- 36 Para aprofundar, cf. Boaventura de Sousa Santos, *La reinención del Estado y el Estado plurinacional*, passim.
- 37 Agustín Grijalva, op. cit., p. 118.
- 38 Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, *Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino*, passim. Cf., ainda, da mesma autora, *Aos 20 anos da Convenção 169 da OIT: balanço e desafios da implementação dos direitos dos povos indígenas na América Latina*, p. 25-31.
- 39 Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, *El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización*, p. 139-140 (tradução livre).
- 40 Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, *El horizonte...*, cit., p. 140.
- 41 Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, *El horizonte...*, p. 140-141.
- 42 A tabela, bem como as citações, foi retirada de Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, *Aos 20 anos da Convenção 169 da OIT: balanço e desafios da implementação dos direitos dos povos indígenas na América Latina*, p. 25-29. E, como bem descreve a ilustre

pesquisadora, “as reformas constitucionais mais importantes ocorridas nas últimas três décadas impactaram a própria definição do modelo de Estado e reconfiguraram a relação jurídica entre os Estados e os povos indígenas. Estas reformas foram feitas segundo o horizonte do Convênio 169 da OIT; com exceção do Chile, todos os países andinos mudaram a Constituição (Colômbia em 1991, Peru em 1993, Bolívia em 1994-2007, Equador em 1998 e 2008, e Venezuela em 1999) incorporando elementos do Convênio 169. Entre tais reformas, cabe ressaltar as que seguem: a) o reconhecimento do caráter pluricultural do Estado/Nação/República, e o direito à identidade cultural, individual e coletiva. O que permite superar a ideia de Estado-nação monocultural e monolíngue; b) o reconhecimento da igual dignidade das culturas, que rompe com a supremacia institucional da cultura ocidental sobre as demais; c) o caráter do sujeito político dos povos e comunidades indígenas e campesinas. Os povos indígenas têm direito ao controle das suas instituições políticas, culturais e sociais e seu desenvolvimento econômico. O que permite superar o tratamento tutelar desses povos, como objeto de políticas que ditam terceiros; d) o reconhecimento de diversas formas de participação, consulta e representação direta de povos indígenas, campesinos e afrodescendentes. O que supera a ideia de que apenas os funcionários públicos representam e podem formar a vontade popular; e) o reconhecimento do direito (consuetudinário) indígena e a jurisdição especial. Isto supõe uma forma de pluralismo jurídico interno. Todos os países andinos incorporaram na Constituição alguma fórmula de pluralismo legal reconhecendo autoridades indígenas ou campesinas, funções de justiça ou jurisdicionais, e o direito indígena ou suas próprias normas e procedimentos; f) junto a isso, o reconhecimento de um conjunto de direitos relativos à terra, as formas organizacionais coletivas, educação bilingue intercultural, oficialização de idiomas indígenas, etc.” (op. cit., p. 30-31).

- 1 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 40.
- 2 Para um estudo mais detalhado da matéria *vide capítulo 4*, sobre o Poder Constituinte.
- 3 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 41.
- 4 Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, p. 20.
- 5 *Elementos de direito constitucional*, p. 19.
- 6 Constituição histórica em Kelsen, explica Fábio Ulhoa Coelho, “será aquele texto fundamental cuja elaboração não se encontra prevista em nenhuma disposição normativa anterior; aquele cujos editores não foram investidos de competência por nenhuma outra norma jurídica. Para nos valermos da expressão de Kelsen, a primeira Constituição histórica deriva da *revolução* na ordem jurídica, tendo em vista que não encontra suporte nesta ordem, mas inaugura uma nova” (*Para entender Kelsen*, p. 31).
- 7 J. H. Meirelles Teixeira, *Curso de direito constitucional*, p. 58-59, e importante discussão do tema nas páginas 58-79.
- 8 J. H. Meirelles Teixeira, *Curso de direito constitucional*, p. 77-78.
- 9 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 1339.
- 10 Virgílio Afonso da Silva, *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*, p. 107-131.
- 11 Op. cit., p. 111.
- 12 Op. cit., p. 112-113.
- 13 Op. cit., p. 113.
- 14 Op. cit., p. 115.
- 15 Op. cit., p. 116. E o autor, em outra passagem, retoma o conceito: “... a ideia de Constituição como **moldura** significa que a Constituição e os direitos fundamentais não só impõem deveres e vedações, mas também deixam ‘espaços abertos’, para os quais a Constituição não tem uma resposta e que devem, por conseguinte, ser preenchidos pelo legislador e, subsidiariamente, pelos operadores do direito e pelos particulares nas suas relações entre si. Nesse sentido, Alexy resume que aquilo que a Constituição deixa em aberto é o que se encontra no interior da moldura e aquilo que ela impõe ou proíbe constitui a moldura em si” (op. cit., p. 120). Nesses termos, o autor reconhece que a

proposta da Constituição-moldura assegura, também, uma **alternativa à teoria dos princípios**, cujos críticos a igualam à Constituição-total. “Segundo esses críticos, se os princípios constitucionais são mandamentos de otimização, que devem ser realizados na maior medida possível dentro das condições fáticas e jurídicas existentes, ao legislador e aos outros ramos do direito sobraria apenas uma tarefa: a de *otimizador* de direitos fundamentais e da Constituição” (op. cit., p. 117-118).

16 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, 7. ed., p. 1386 e 1387.

17 Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite*, p. 8-11.

18 Para um detalhado relato da experiência da Islândia, cf. Thorvaldur Gylfason, From collapse to Constitution: the case of Iceland, in: Luigi Paganetto Editor, *Public Debt, Global Governance and Economic Dynamism*, p. 379-417. O autor é Professor de Economia da Universidade da Islândia e um dos 25 representantes do Conselho Constitucional (Assembleia Constituinte), eleito pelo povo e reconhecido pelo Parlamento para a revisão da Constituição de 1944.

19 A palavra **crowdsourcing** é recente e o seu surgimento data do ano de **2005**, conforme descrito: “the activity or practice of involving a great many people to develop ideas, produce content, or accomplish huge or tedious tasks, as by **soliciting help via the internet**. The word originated as a convenient compound to denote ‘**outsourcing to the crowd**’” (Bryan A. Garner, *Black’s law dictionary*, 10. ed., p. 459).

20 Trata-se de projeto promovido pelo Instituto de Assuntos Públicos (IPA — Institute of Public Affairs) da Escola de Economia de Londres (LSE) em conjunto com o seu departamento de direito e seu grupo de políticas públicas e auditorias democráticas. Nesse sentido, cf.: a) **site**: <<http://constitutionuk.com>>; b) **Twitter**: @constitutionUK; c) **Facebook**: <<http://www.facebook.com/ConstitutionUK>>.

21 Cf.: <<http://edemocracia.camara.gov.br/o-que-e>>.

22 De acordo com o art. 2.º, do *Ato da Mesa n. 3/2011*, o Programa e-Cidadania do Senado Federal, baseado no uso da *internet* e outros canais de comunicação interativos, tem os seguintes objetivos: I — ampliar o conhecimento da sociedade sobre o funcionamento do Poder Legislativo, em especial do Senado Federal e do Congresso Nacional; II — aprimorar o fornecimento de informações sobre as atividades do Senado Federal; III — obter dos cidadãos sua avaliação sobre os resultados das ações legislativas e fiscalizadoras do Congresso Nacional; IV — fomentar a **participação da sociedade**

nas discussões dos temas legislativos em pauta, assim como no processo de definição, execução e avaliação de políticas públicas; V — proporcionar mecanismos pelos quais os cidadãos brasileiros possam oferecer **sugestões de textos legislativos**, em conformidade com os preceitos constitucionais e regimentais estabelecidos; VI — estimular o **engajamento** dos cidadãos brasileiros no **processo democrático**.

23 a) **Twitter**: @edemocracia; b) **Facebook**: <<http://www.facebook.com/edemocracia>>; c) **Youtube**: <<http://www.youtube.com/edemocraciacd>>.

24 Referido tema foi exigido, dentre outros, no edital do **IV Concurso para ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo** (2010). A apresentação se dará de acordo com o trabalho: Marcelo Neves, *A constitucionalização simbólica*, Col. Justiça e Direito, passim. O tema também foi objeto do programa **“Aula Magna”** da TV Justiça e pode ser assistido em: <<http://www.youtube.com/watch?v=l5V5uTLfi2c>> (“A Constitucionalização Simbólica Revisitada”).

25 Marcelo Neves, op. cit., passim.

26 Marcelo Neves, op. cit., p. 1.

27 Marcelo Neves, op. cit., p. 23 (grifamos).

28 Marcelo Neves, op. cit., p. 34.

29 Marcelo Neves, op. cit., p. 35.

30 Marcelo Neves, op. cit., p. 39-40.

31 Marcelo Neves, op. cit., p. 40-41.

32 Marcelo Neves, op. cit., p. 41.

33 Marcelo Neves, op. cit., p. 42.

34 Marcelo Neves, op. cit., p. 65.

35 Marcelo Neves, op. cit., p. 90-101.

36 Marcelo Neves, op. cit., p. 142.

37 Marcelo Neves, op. cit., p. 176.

38 Marcelo Neves, op. cit., p. 188-189.

39 Écio Oto Ramos Duarte, *Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico*, p. 24.

- 40 Por esse motivo, alguns autores classificam as **cesaristas** como **Constituições bonapartistas** (por se tratar de um método utilizado por *Napoleão Bonaparte* nos referidos plebiscitos napoleônicos) (cf. R. C. Chimenti, F. Capez, M. F. E. Rosa, M. F. Santos, *Curso de direito constitucional*, 6. ed., p. 9).
- 41 *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 44 — original sem grifos.
- 42 R. C. Chimenti, F. Capez, M. F. E. Rosa, M. F. Santos, *Curso de direito constitucional*, 6. ed., p. 9.
- 43 *Constituição Federal anotada*, p. 9.
- 44 Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 9. ed., p. 72.
- 45 R. C. Chimenti, F. Capez, M. F. E. Rosa, M. F. Santos, *Curso de direito constitucional*, 2004, p. 9.
- 46 Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 84. Para aprofundamento da matéria, por todos, René David, *Os grandes sistemas do direito contemporâneo*, p. 331-355. Virgílio Afonso da Silva, nessa linha e avançando, observa: “no Brasil, todos costumam mencionar a Constituição inglesa como o modelo de constituição não escrita e flexível. Essa categorização está tão sedimentada no pensamento constitucional brasileiro que a discussão acerca da aprovação (1998) e da entrada em vigor (2000), na Inglaterra, do *Human Rights Act*, que pôs em cheque a ideia de supremacia do parlamento inglês, ainda não foi percebida por aqui. Ocorre que a supremacia do parlamento é justamente o reflexo do que a doutrina brasileira costuma chamar de constituição flexível. Se o parlamento inglês já não é mais soberano no sentido tradicional, e deve respeitar as disposições da declaração de direitos, o modelo de constituição flexível também cai por terra” (*A constitucionalização do direito*, p. 109, nota 6. Para aprofundamento em relação a essa mencionada tensão entre a supremacia do parlamento e a entrada em vigor do *Human Rights Act* na Inglaterra, cf., por todos, Nicholas Bamforth, *Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act 1998*, Public Law 1998, p. 572-582).
- 47 Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 84-85.
- 48 Pinto Ferreira, *Curso de direito constitucional*, 10. ed., p. 66.
- 49 Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 91.
- 50 Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 9. ed., p. 74.
- 51 J. H. Meirelles Teixeira, *Curso de direito constitucional*, p. 105-106.

- 52 *Curso de direito constitucional*, p. 19.
- 53 *Elementos de direito constitucional*, p. 26.
- 54 *Curso de direito constitucional*, p. 4.
- 55 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 42-43.
- 56 *Direito constitucional*, p. 37.
- 57 *Curso de direito constitucional*, p. 12.
- 58 *Curso de direito constitucional*, p. 12. **CUIDADO:** em outro sentido, Raul Machado Horta considera a Constituição brasileira de 1988 **plástica**, na medida em que permite o preenchimento das regras constitucionais pelo legislador infraconstitucional. Assim, o conceito de Constituição plástica para Pinto Ferreira (em seu entender, aquelas flexíveis — critério quanto à alterabilidade) não é o mesmo para Raul Machado Horta. Para este último, “a Constituição plástica estará em condições de acompanhar, através do legislador ordinário, as oscilações da opinião pública e da vontade do corpo eleitoral. A norma constitucional não se distanciará da realidade social e política. A Constituição normativa não conflitará com a Constituição real. A coincidência entre a norma e a realidade assegurará a duração da Constituição no tempo” (*Direito constitucional*, 4. ed., p. 211).
- 59 Desenvolveremos melhor este tema quando tratarmos das emendas constitucionais, no item 9.14.1.
- 60 *Direito constitucional*, 14. ed., p. 274-275.
- 61 *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 45.
- 62 Como observa Celso Bastos, “... hoje em dia já se toma por absurdo que um Texto Constitucional se pretenda perpétuo, quando se sabe que é destinado a regular a vida de uma sociedade em contínua mutação...” (*Curso de direito constitucional*, p. 51).
- 63 *Direito constitucional*, 23. ed., p. 10.
- 64 Taxação dos inativos — **“princípio da solidariedade”** (ADI 3.105/DF e ADI 3.128/DF, Rel. orig. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, 18.08.2004).
- 65 Pinto Ferreira, *Curso de direito constitucional*, p. 13.
- 66 Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 88.
- 67 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 218.

- Barroso também percebe essa dialética, salientando o equilíbrio entre os interesses do capital e do trabalho. Destaca, de um lado, a **livre-iniciativa** e, de outro, regras de **intervenção do Estado no domínio econômico**, havendo contemplação de direitos sociais dos trabalhadores e restrições ao capital estrangeiro (cf. Luís Roberto Barroso, *Temas de direito constitucional*, p. 11-12).
- 68 Pinto Ferreira, *Curso de direito constitucional*, 10. ed., p. 13.
- 69 Guilherme Peña de Moraes, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 69.
- 70 Marcelo Neves, *A constitucionalização simbólica*, p. 101-110. Sobre a temática da constitucionalização simbólica, cf. *item 2.3*.
- 71 *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 67, destacando Diogo de Figueiredo Moreira Neto, *Mutações do direito administrativo*, 2000, p. 81.
- 72 Jorge Miranda, *Manual de direito constitucional*, 5. ed., 2003, t. II, p. 108.
- 73 Miguel Galvão Teles, *Constituição*, in *Verbo*, V, p. 1500, apud Jorge Miranda, *Manual...*, t. II, 5. ed., 2003, p. 96.
- 74 Jorge Miranda, *op. cit.*, p. 96-97.
- 75 Jorge Miranda, *op. cit.*, p. 97.
- 76 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, 34. ed., p. 14-15.
- 77 *Curso de direito constitucional*, 6. ed., p. 74.
- 78 *Direito constitucional*, 4. ed., p. 207-210.
- 79 Luiz Sales do Nascimento, *Direito constitucional comparado: pressupostos teóricos e princípios gerais*, *passim*.
- 80 J. H. Meirelles Teixeira, por exemplo, vislumbra quatro categorias de elementos, a saber: **orgânicos**, **limitativos**, **programático-ideológicos** e **formais** ou de **aplicabilidade** (*Curso de direito constitucional*, p. 183-184).
- 81 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 44-45.
- 82 Este tema passou a ser inserido nos programas dos editais das provas mais recentes e consta, inclusive, no Edital de 28.12.2007 do Concurso de admissão à *Carreira de Diplomata*.
- 83 Sem contar os meses e os dias.

- 84 15.11.1889 — instalação do Governo Provisório da República.
- 85 Conforme se verá no *item 2.5.4*, a chamada *República Velha* tem o seu fim com a *Revolução de 1930*, que instituiu, por meio de uma Junta Militar, o Governo Provisório, nos termos do **Decreto n. 19.398, de 11.11.1930**, levando Getúlio Vargas ao poder, perdurando até a promulgação do texto de 1934.
- 86 Em razão de seu caráter revolucionário, posicionamo-nos no sentido de considerar a **EC n. 1/69** um novo **poder constituinte originário**.
- 87 Até o fechamento desta edição.
- 88 Nesse sentido e para aprofundar a evolução histórica do Município Neutro e do Distrito Federal, cf. Vitor Fernandes Gonçalves, *O controle de constitucionalidade das leis do Distrito Federal*, p. 15-45.
- 89 Conforme anota Celso Bastos, em determinado momento da monarquia, “... floresceu uma prática parlamentarista que acabou por implantar no País um regime que o texto frio da Constituição não autorizava, mas ao contrário vedava. A monarquia esteve, portanto, muito ligada ao sistema parlamentar. Inspirou-se muito no regime inglês e no século XIX, sem falar na própria Inglaterra, que foi a *alma mater* do regime representativo...” (*Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 102).
- 90 Afonso Arinos de Melo Franco, *O constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal*, p. 28.
- 91 Afonso Arinos de Melo Franco, *op. cit.*, p. 28-29.
- 92 Como anotou Celso Bastos, “o liberalismo tem por ponto central colocar o homem, individualmente considerado, como alicerce de todo o sistema social” (*Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 98).
- 93 Nesse sentido, cf. Pinto Ferreira, *Curso de direito constitucional*, 10. ed., p. 50.
- 94 Destacamos, anteriormente, apenas para recordar, a Lei n. 2.040, de 28.09.1871 (“Lei do Ventre Livre”), que assegurou a condição de livres aos filhos da mulher escrava, bem como a “Lei dos Sexagenários”, que tornou livres, a partir de 1885, os escravos com idade igual ou superior a 65 anos.
- 95 Segundo José Afonso da Silva, o Distrito Federal tem origem histórica no federalismo norte-americano, nos termos do art. 1.º da Seção 8, n. 17, da Constituição americana de 1787. Isso porque “... a autonomia das entidades federativas regionais entre si e em

relação à União e do governo desta em face daquelas exigiu que a sede do governo federal se localizasse em território sujeito à sua própria jurisdição. Foi assim que surgiu o *Distrito Federal*, como mais uma inovação da história constitucional dos Estados Unidos...” (*Comentário contextual à Constituição*, 2. ed., p. 318 — comentários ao art. 32).

96 Para informações históricas sobre o período republicano da política brasileira e a galeria dos Presidentes, cf.: <<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes>>.

97 Convém lembrar que o Decreto n. 774, de 20.09.1890, expedido durante o Governo Provisório da República, já havia: *a*) abolido a pena de galés; *b*) reduzido a 30 anos as penas perpétuas; *c*) mandado computar a prisão preventiva na execução; *d*) estabelecido a prescrição das penas. Destacamos, também, os “considerandos”, que apontam avanços em termos de direitos humanos, explicando, ainda, o conceito de pena de galés: “Que as penas cruéis, infamantes ou inutilmente aflitivas não se compadecem com os princípios da humanidade, em que no tempo presente se inspiram a ciência e a justiça sociais, não contribuindo para a reparação da ofensa, segurança pública ou regeneração do criminoso; Que as galés impostas pelo código criminal do extinto império obrigando os réus a trazerem *calceta* no pé e corrente, infligem uma tortura e um estigma, enervam as forças físicas e abatem os sentimentos morais, tornam odioso o trabalho, principal elemento de correção, e destroem os estímulos da reabilitação; Que a Constituição da República, embora ainda não em vigor nesta parte, já determinou a abolição dessa pena; Que a penologia moderna reprova igualmente a prisão perpétua; Que a justiça penal tem limite na utilidade social, devendo cessar, ainda depois da condenação e durante a execução, a pena abolida pelo poder público; Que urge, enquanto não é publicado e posto em execução o novo Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, remediar excessivos rigores da legislação criminal vigente, entre os quais a imprescritibilidade da pena, decreta...”.

98 Conforme anota Carlos Fernando Mathias de Souza, “eram as seguintes as **penas** do Código de 1830: **de morte pela força** (art. 38), inadmitindo rigores na execução (art. 61), aplicada contra cabeças de insurreição (arts. 113 e 114) e em determinadas hipóteses de homicídios, é dizer-se, em função de determinadas circunstâncias (arts. 192 e 271). A **pena de galés**, que era aplicada como comutação da pena de morte ou (em grau mínimo) para os crimes de perjúrio, pirataria ou de ofensa física irreparável da qual resultasse aleijão ou deformidade. Os punidos com ela deviam andar com calceta no pé e corrente de ferro, além de serem obrigados a trabalhos públicos. A **pena de prisão** era estabelecida

para a quase que totalidade dos crimes. A de banimento consistia em autêntica *capitis diminutio* do *status civitatis* posto que privava o condenado dos seus direitos de cidadão, além de impedi-lo de residir no território do império. É curioso, contudo, observar que não se encontra no Código qualquer crime para o qual fosse estabelecida tal pena. Outra pena, a de **degredo**, obrigava o punido a residir em determinado lugar e por certo tempo (art. 51) e estava cominada para réus que cometessem estupro de parente em grau em que não fosse admitida dispensa para o casamento (art. 221) ou para quem sem legitimidade ou investidura legal exercesse comando militar ou conservasse a tropa reunida abusivamente (art. 141). A **pena de desterro**, que consistia na saída do condenado do local onde foi praticado o delito, do de sua principal residência e do ofendido, era aplicada nas hipóteses de conspiração, abuso de autoridade, crime de estupro e de sedução de mulher com menos de dezessete anos. A **perda de exercício dos direitos políticos** era uma espécie de **pena acessória**, aplicada enquanto durassem os efeitos da condenação às galés, à prisão, ao degredo ou ao desterro — (art. 53). A **pena de perda do emprego (público)** destinava-se aos funcionários que cometessem os crime de prevaricação, de peita, de excesso ou abuso de autoridade, dentre outros. Já a **pena de suspensão de emprego** era estabelecida para as hipóteses, por exemplo, da prática de concussão”. A **pena de açoites** só podia ser aplicada aos escravos e desde que não condenados à pena capital, ou de galés, ou ainda por crime de insurreição. Lembre-se que havia, ainda, a **pena de multa**, que, obviamente, consistia no pagamento de pecúnia e era aplicada aos condenados à pena maior, quer por crimes públicos, particulares ou policiais (cf.: <http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/carlos_mathias/anterior_16.htm>; acesso em: 28.11.2007).

99 Celso Bastos, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 110.

100 Conforme anota, com razão, Pinto Ferreira, “provavelmente a revolução não teria eclodido na época se não fosse a sucessão presidencial. Washington Luís forçou a sucessão em favor de Júlio Prestes, candidato de São Paulo, quando Antônio Carlos pleiteava a sucessão apoiado por Minas Gerais. De acordo com o esquema de controle da presidência (‘política do café com leite’, acrescente-se), São Paulo e Minas se revezavam mutuamente. Washington Luís não atendeu a essa pretensão, o que acelerou a revolução.

Esta propagou-se rapidamente, com o apoio do povo, dos estudantes, dos operários e das Forças Armadas, estas últimas depondo o presidente em 24.10.1930, e compondo-se uma junta governativa provisória (...). A junta transmitiu o governo ao candidato derrotado eleitoralmente, o Sr. Getúlio Vargas, em 03.11.1930. Logo em seguida, foi expedida a Lei

Orgânica do Governo Provisório, pelo Decreto n. 19.398, de 11.11.1930, a fim de organizar a nova República” (*Curso de direito constitucional*, 10. ed., p. 54).

101 Luís Roberto Barroso, *O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira*, 8. ed., p. 14-19.

102 Conforme anota Zimmermann, “ainda que tenha se revelado um completo fracasso do ponto de vista militar (os seus líderes foram presos pelas forças governistas), a Revolução de 1932 foi um sucesso absoluto do ponto de vista político, porque Getúlio se sentiu forçado a consentir na elaboração de uma nova Constituinte, em 1933, que marcaria o retorno à normalidade constitucional” (Augusto Zimmermann, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 205).

103 Apenas por curiosidade, destacamos que a potiguar *Celina Guimarães Vianna*, da cidade de Mossoró, foi a primeira eleitora do Brasil (e na América Latina). No caso, tratava-se de garantia inicialmente introduzida no Código Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte (Lei estadual n. 660/27), lembrando que a previsão nacional veio somente com o Código Eleitoral (Dec. n. 21.076, de 24.02.1932). Em razão dessa conquista ter sido assegurada pelo referido Código, a sua data, qual seja, **24 de fevereiro**, foi instituída, no Calendário Oficial do Governo Federal, como o **Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil**, a ser comemorado, anualmente (**Lei n. 13.086, de 08.01.2015**).

104 José Afonso da Silva, *Processo constitucional de formação das leis*, 2. ed., p. 74.

105 Nesse sentido, nos termos do art. 23, § 3.º, os Deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária por sufrágio indireto das associações profissionais compreendidas para esse efeito, e com os grupos afins respectivos, nas quatro divisões seguintes: lavoura e pecuária; indústria; comércio e transportes; profissões liberais e funcionários públicos.

106 Conforme Celso Bastos explica, “era como que a reconstituição do Poder Moderador do Império, transformado em órgão supremo do Estado. Marcelo Caetano vê nele semelhanças com o Senado Conservador das Constituições francesas do ano VIII e do ano X” (*Curso de direito constitucional*, p. 114).

107 Muito embora o texto de 1824 falasse em ação popular nos termos do art. 157 (“por suborno, peita, peculato, e concussão, haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida na Lei”), parece que esta se referia a certo caráter

disciplinar ou mesmo penal. Assim, concordamos com Mancuso que o texto de 1934 foi “o primeiro texto constitucional que lhe deu guarida” (Rodolfo de Camargo Mancuso, *Ação popular*, 4. ed., p. 52). Cf. interessante evolução histórica do instituto trazida por José Afonso da Silva, *Ação popular constitucional*, p. 28-39.

108 Nesse sentido, Luís Roberto Barroso, *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*, p. 23.

109 Luís Roberto Barroso, *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*, p. 24. Também nesse sentido, Pinto Ferreira, *Curso de direito constitucional*, 10. ed., p. 57.

110 O Texto de 1946 sofreu 21 emendas constitucionais, 4 Atos Institucionais e 37 Atos Complementares.

111 Celso Bastos, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 134.

112 Celso Bastos, *Curso de direito constitucional*, 21. ed., p. 134 (grifamos).

113 Como anota Bastos, “o AI-5 marca-se por um autoritarismo ímpar do ponto de vista jurídico, conferindo ao Presidente da República uma quantidade de poderes de que muito provavelmente poucos déspotas na história desfrutaram, tornando-se marco de um novo surto revolucionário, dando a tônica do período vivido na década subsequente” (*Curso de direito constitucional*, p. 136).

114 Pedimos vênia para reproduzir os “considerandos” da EC n. 1/69, que, *sinistramente*, buscava justificar o **ato autoritário** baixado pela Junta Militar: “Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3.º do AI-16, de 14.10.1969, combinado com o § 1.º do artigo 2.º do AI-5, de 13.12.1968, e *considerando* que, nos termos do Ato Complementar n. 38, de 13.12.1968, foi decretado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Nacional; *considerando* que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo Federal fica autorizado a legislar sobre todas as matérias, conforme o disposto no § 1.º do art. 2.º do AI-5, de 13.12.1968; *considerando* que a elaboração de emendas à Constituição, compreendida no processo legislativo (artigo 49, I), está na atribuição do Poder Executivo Federal; (...), *promulgam* a seguinte Emenda à Constituição de 24 de janeiro de 1967: Art. 1.º A Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte redação...”.

115 Esse momento faz surgir no País o ufanismo (orgulho exacerbado pelo Brasil; patriotismo excessivo), percebido em frases como: “Brasil, ame-o ou deixe-o”.

116 Sobre o assunto, cf. Rodolfo de Camargo Mancuso, *Divergência jurisprudencial e*

súmula vinculante, p. 313-324. A advocatória não foi mantida no texto de 1988, devendo eventual pedido feito antes do advento da CF/88 ser julgado prejudicado. Nesse sentido, cf. PAV-QO 16/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 12.10.1988, Pleno, *DJ* de 25.11.1988, p. 31055. “Avocação de causas a requerimento da Procuradoria-Geral da República. Pedido fundado no art. 119, I, ‘o’ da CF de 1967, c/ a redação das Emendas 1/69 e 7/77. Liminar deferida pelo presidente do STF e prorrogada pelo relator. Superveniência da CF de 5.10.1988, que não previu o instituto da advocatória para o STF ou para qualquer outro tribunal. Extinção do instituto político-processual. Pedido que se julga prejudicado, em questão de ordem, com revogação da medida liminar”. Também, como anota Gilmar Ferreira Mendes, a ação declaratória de constitucionalidade, introduzida pela EC n. 3/93 à CF/88, não deve ser confundida com a advocatória do regime totalitário. Isso porque “... a) a competência do STF será originária e não decorrencial; b) os motivos para sua proposição serão ‘jurídicos’ e não meramente ‘políticos’; c) não haverá interferência direta nas decisões de 1.ª instância suspendendo sua eficácia sem fundamentos jurídicos, mas decisão definitiva sobre a questão suscitada” (A ação declaratória, in I. G. da S. Martins e G. F. Mendes, *Ação declaratória de constitucionalidade*, p. 82).

117 Como anota Celso Bastos, “mantêm-se, todavia, a lei de segurança nacional (Lei n. 6.620, de 17.12.1978, acrescente-se), os ‘biônicos’ e a Lei Falcão. Sem embargo, não se concede a reclamada anistia geral. De outra parte, fica autorizada a decretação de estado de emergência e das medidas de emergência” (*Curso de direito constitucional*, p. 143).

118 Nesse sentido, destacamos a **Lei n. 12.486/2011**, que também inclui o nome do cidadão **Pedro Aleixo** na “**galeria dos que foram ungidos pela Nação Brasileira para a Suprema Magistratura**”. Lembrando a história, estando o Presidente da República, *Marechal Arthur da Costa e Silva*, temporariamente impossibilitado do exercício de suas funções por motivo de saúde, a *Junta Militar trina* editou o famigerado **AI 12**, de 1.º.09.1969, estabelecendo que enquanto durasse o afastamento temporário do Presidente da República, pelo referido motivo de saúde, as suas funções seriam exercidas pelos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, **impedindo**, assim, e contrariando a Constituição, que o Vice-Presidente da República, Pedro Aleixo, assumisse o cargo. Em seguida, o **AI 16**, de 16.10.1969, declarou a **vacância em definitivo** dos cargos e fixou data para eleições e posse de Presidente e Vice-Presidente da República, permanecendo, nesse período, o exercício da Presidência da República com os Ministros militares.

119 Segundo José Afonso da Silva, “em verdade, a EC n. 26, de 27.11.85, ao convocar a

Assembleia Nacional Constituinte, constitui, nesse aspecto, um ato político. Se convoca a Constituinte para elaborar Constituição nova que substituirá a que estava em vigor, por certo não tem a natureza de emenda constitucional, pois esta tem precisamente sentido de manter a Constituição emendada. Se visava destruir esta, não pode ser tida como emenda, mas como ato político” (*Curso de direito constitucional positivo*, 27. ed., p. 87).

¹²⁰ Luís Roberto Barroso, *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*, p. 41-42.

¹²¹ Prezado leitor, conferir se não há alguma emenda nova!

¹²² Cf. o nosso *Teoria geral da ação civil pública*, 3. ed., *passim*.

1 O tema da **hermenêutica** ganha importância para os concursos públicos. Remetemos, por esse motivo e em razão da especificidade da matéria, o nosso ilustre leitor para as **obras monográficas**, destacando-se: H. **Ávila**, *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*, passim; L. R. **Barroso**, *Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*, passim; L. V. A. da **Silva** (org.), *Interpretação constitucional*, passim e, do mesmo autor, *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*, passim. P. **Bonavides**, *Curso de direito constitucional*, várias passagens; I. M. **Coelho**, *Interpretação constitucional*, passim; L. L. **Streck**, *Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito*, passim; idem: *Jurisdição constitucional e hermenêutica*, passim; J. A. L. **Sampaio**, *A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional*, passim; F. A. **Vasconcellos**, *Hermenêutica jurídica e derrotabilidade*, passim; P. **Häberle**, *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição — contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição*, passim; K. **Hesse**, *A força normativa da Constituição*, passim; R. **Dworkin**, *Taking rights seriously*, passim (trad. para o português, *Levando os direitos a sério*, 3. ed., 2010, WMF Martins Fontes); R. **Alexy**, *Teoria dos direitos fundamentais*, passim; clássicos como C. **Maximiliano**, *Hermenêutica e aplicação do direito*, passim, dentre vários outros trabalhos importantes.

2 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior observam que “a norma constitucional é autolegitimante, ou seja, colocando-se no vértice superior da pirâmide, é o polo irradiador de legitimação no interior do sistema jurídico. Se serve de anteparo para as normas infraordenadas, não tem assento em qualquer disposição normativa, pois que sobre si nada encontra” (*Curso de direito constitucional*, p. 49).

3 Na medida em que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (art. 5.º, § 3.º, EC n. 45/2004), podemos pensar nessa nova modalidade de “reforma”.

4 *Constituição Federal anotada*, p. 22. O autor, em interessante compilação, lembra as diversas denominações terminológicas atribuídas ao fenômeno das mudanças informais das constituições ou meios difusos de modificação constitucional: vicissitude constitucional tácita, mudança constitucional silenciosa (*stillen Verfassungswandlungen*), transições

constitucionais, processos de fato, mudança material, processos indiretos, processos não formais, processos informais, processos oblíquos, mutação constitucional, mudanças informais etc. (p. 23).

- 5 Luís Roberto Barroso, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 126-127.
- 6 Olavo Alves Ferreira, *Controle de constitucionalidade e seus efeitos*, nota 112, p. 140.
- 7 Luís Roberto Barroso, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 130-136.
- 8 Sobre o assunto, cf., ainda, José Afonso da Silva, *Poder constituinte e poder popular*, p. 286.
- 9 *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 1159.
- 10 H. Ávila, *Teoria dos princípios*, 10. ed., p. 120-1.
- 11 *Teoria dos princípios*, 10. ed., p. 144-185.
- 12 *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 1160-1 (redação igual ao original).
- 13 L. R. Barroso, *Interpretação e aplicação da Constituição*, 7. ed., p. 353.
- 14 Nesse sentido, cf. R. Dworkin, *Taking rights seriously*, passim. (Há tradução para o português: *Levando os direitos a sério*, 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.)
- 15 R. Alexy, *Teoria dos direitos fundamentais*, p. 90-91 (trad. de Virgílio Afonso da Silva) (grifamos). Cf., também, sobre a **distinção entre regras e princípios**, L. V. A. da Silva, Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção, *Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais*, p. 607-630. Barroso, por seu turno, refere-se (na tradução do original do alemão) à expressão **mandados de otimização** (princípios) e **mandados de definição** (regras) (*Interpretação e aplicação da Constituição*, 7. ed., p. 357, nota 23).
- 16 L. V. A. da Silva, *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*, p. 121.
- 17 L. R. Barroso, *Interpretação e aplicação da Constituição*, 7. ed., p. 357-358. Nesse sentido, reconstruindo a distinção entre princípios e regras, por todos, H. Ávila, *Teoria dos princípios*, passim.
- 18 Para aprofundamento da matéria, cf. interessante estudo de F. A. Vasconcellos, *Hermenêutica jurídica e derrotabilidade*, passim. Ainda, sob o aspecto de *modelos*

- lógicos* (“refinamento de teorias”), cf. J. S. de A. Maranhão, *Padrões de racionalidade na sistematização de normas* (tese de doutorado FADUSP). Interessante, também, o debate entre Bayón e Rodríguez sobre a matéria: J. C., Bayón; J. Rodríguez Russo, *Relevancia normativa en la justificación de las decisiones judiciales*: El debate Bayón-Rodríguez sobre la derrotabilidad de las normas jurídicas (também em formato *e-book*). Para a discussão no âmbito processual (*derrotabilidade processual* atrelada à ideia de ônus da prova), Vasconcellos destaca os estudos de Giovanni Sartor e Neil MacCornmick (op. cit., p. 100-106).
- 19 H. Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 112-114.
- 20 H. Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 112-114.
- 21 H. L. A. Hart, The Ascription of Responsibility and Rights, apud Vasconcellos, *Hermenêutica jurídica e derrotabilidade*, p. 54.
- 22 Conforme afirma, “... as regras têm **eficácia de trincheira**, pois, embora geralmente superáveis, só o são por razões extraordinárias e mediante um ônus de fundamentação maior” (*Teoria dos princípios*, p. 119).
- 23 H. Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 117.
- 24 F. A. Vasconcellos, *Hermenêutica jurídica e derrotabilidade*, p. 88.
- 25 A Universidade Federal de Goiás — UFGO interpôs recurso extraordinário (**RE 593.428**) contra o referido acórdão da 6.^a Turma do TRF1, que teve, em decisão monocrática do Min. Dias Toffoli proferida em 13.10.2011, o seu **seguimento negado**, com base na jurisprudência dominante firmada na ADI 3324. Apenas observamos que, lendo referida decisão, o Min. Toffoli não analisa a questão da derrotabilidade, tratando o assunto como se fosse o caso típico de instituição congênere.
- 26 Referido julgado pode ser encontrado em: <http://www.go.trf1.gov.br/institucional/turma_recursal/acordaos/2005/it20051214.htm>. O Juiz Relator, **Juliano Taveira Bernardes**, doutrinariamente, já havia tratado do assunto ao justificar a possibilidade de **aborto do feto anencefálico**, com base na ideia de **derrotabilidade**. Cf. Aborto de feto anencefálico e “derrotabilidade”, *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 617, 17 mar. 2005.
- 27 H. Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 123-181.
- 28 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 212-213.

- 29 I. M. Coelho, *Interpretação constitucional*, p. 91.
- 30 I. M. Coelho, *Interpretação constitucional*, p. 93.
- 31 I. M. Coelho, *Interpretação constitucional*, p. 94.
- 32 Segundo Canotilho, “a elaboração (indutiva) de um catálogo de tópicos relevantes para a interpretação constitucional está relacionada com a necessidade sentida pela doutrina e *praxis* jurídicas de encontrar princípios tópicos auxiliares da tarefa interpretativa: (1) relevantes para a decisão (= resolução) do problema prático (princípio da relevância); (2) metodicamente operativos no campo do direito constitucional, articulando direito constitucional formal e material, princípios jurídico-funcionais (ex.: princípio da interpretação conforme a Constituição) e princípios jurídico-materiais (ex.: princípio da unidade da Constituição, princípio da efetividade dos direitos fundamentais); (3) constitucionalmente praticáveis, isto é, susceptíveis de ser esgrimidos na discussão de problemas constitucionais dentro da ‘base de compromisso’ cristalizada nas normas constitucionais (princípio da praticabilidade)” (J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 226).
- 33 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 226.
- 34 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 227.
- 35 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 227.
- 36 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 228.
- 37 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 228.
- 38 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 229.
- 39 Gilmar Ferreira Mendes, em apresentação ao trabalho de **Konrad Hesse**, *A força normativa da Constituição*, que serviu de base para a aula inaugural na Universidade de Freiburg-RFA, em 1959.
- 40 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 229-230.
- 41 K. Larenz, *Metodologia da ciência do direito*, 1989, p. 585-586; *Derecho justo*, p. 144-145.
- 42 I. M. Coelho, *Interpretação constitucional*, p. 109.
- 43 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 184.

- 44 R. Guastini, *Estudios sobre la interpretación jurídica*, México, Porrúa, 2000, p. 47-49, apud G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 185.
- 45 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 185.
- 46 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 186.
- 47 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 186.
- 48 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 1432.
- 49 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 1019.
- 50 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 1432. Cabe alertar, contudo, que, segundo Elival da Silva Ramos, esses exemplos não seriam típicas sentenças aditivas em sentido próprio, “... já que à reconstrução do sentido do dispositivo legal apreciado pela Corte não se atribuiu eficácia *erga omnes* e vinculativa, haja vista a decisão final de improcedência da inconstitucionalidade suscitada, com a ressalva da interpretação conforme” (*Ativismo judicial*, p. 218).
- 51 Houve autorização para que os Ministros do STF apliquem monocraticamente esse entendimento aos mandados de injunção **pendentes** de julgamento, desde que impetrados **antes** do advento da lei regulamentadora (**MI 1.090**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.02.2013, Plenário, *DJE* de 23.04.2013). Contudo, nos termos do voto do Relator, entendeu a Corte **não ser possível**, por **segurança jurídica**, “exigir-se a aplicação dos parâmetros trazidos pela Lei 12.506/2011 para todas as situações jurídicas que se **consolidaram** entre a promulgação da Constituição e a edição da referida lei. Em primeiro lugar, a mora legislativa pressupõe certo lapso temporal de inação, o que não estaria configurado tão logo promulgada a Constituição, mas, além disso, muitas situações já se **consolidaram** de tal modo que a Constituição também lhes atribui proteção, a título de **ato jurídico perfeito** ou de **coisa julgada**” (fls. 48 do acórdão).
- 52 *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 187.
- 53 Lenio Luiz Streck, *Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista”?*, passim.

- 54 *Teoria dos princípios*, 10. ed., p. 144-185.
- 55 Oscar Vilhena Vieira, *Supremocracia*, *Revista Direito GV*, n. 8, p. 444 e 445.
- 56 Op. cit., p. 445.
- 57 O voto do Min. Celso de Mello pode ser lido, na íntegra, em *Notícias/STF* de 23.12.2010.
- 58 “*Es gibt keine Rechtsnormen, es gibt nur interpretierte Rechtsnormen*”, Peter Häberle, *Zeit und Verfassung*, in Dreier, Ralf/Schwegmann, Friedrich, *Probleme der Verfassungsinterpretation*, p. 293 (313).
- 59 Einen Rechssatz “auslegen” bedeutet, ihn in die Zeit, d.h. in die öffentliche Wirklichkeit stellen — um seiner Wirksamkeit willen”, Peter Häberle, *Zeit und Verfassung*, in Dreier, Ralf/Schwegmann, Friedrich, *Probleme der Verfassungsinterpretation*, p. 293 (309).
- 60 Gilmar Ferreira Mendes, apresentação à obra: Peter Häberle, *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição*, Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1997, passim (publicada originariamente em 1975 — “Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten”).
- 61 Peter Häberle, *Zeit und Verfassung*, p. 14.
- 62 Cf. Luís Sérgio Soares Mamari Filho, *A comunidade aberta de intérpretes da Constituição...*, p. 83-106.
- 63 Häberle observa que “os instrumentos de informação dos juízes constitucionais — não apesar, mas em razão da própria vinculação à lei — devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se refere às formas gradativas de participação e à própria possibilidade de participação no processo constitucional (especialmente nas audiências e nas ‘intervenções’). Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição. O direito processual constitucional torna-se parte do direito de participação democrática. A interpretação constitucional realizada pelos juízes pode-se tornar, correspondentemente, mais elástica e ampliativa sem que se deva ou possa chegar a uma identidade de posições com a interpretação do legislador” (*Zeit und Verfassung*, p. 47-48).
- 64 As audiências públicas podem ser acompanhadas no site do STF <<http://www.stf.jus.br/portal/audienciapublica>>. Os temas discutidos, sem dúvida, destacam-se para as provas de

concursos.

65 Para uma visão mais ampla de Constituição, remetemos o nosso ilustre leitor para a teoria do **bloco de constitucionalidade**, estudada no *item 6.7.1.3*.

66 *Estudos sobre a Constituição*, p. 17, apud ADI 2.076-AC, Rel. Min. Carlos Velloso.

67 Julgamento na ADI 2.076-AC, Rel. Min. Carlos Velloso, 15.08.2002, *DJ*, 08.08.2003, e *Inf.* STF ns. 277/2002 e 320/2003, 08 a 12.12.2003.

68 Confira outros aspectos sobre o tema no *item 14.10.6*.

69 Cf.: CF/88 — “sob a proteção de Deus”; CF/67 — “invocando a proteção de Deus”; CF/46 — “sob a proteção de Deus”; CF/37 — *não consta a invocação à proteção de Deus*; CF/34 — “pondo a nossa confiança em Deus”; CF/1891 — *não consta a invocação à proteção de Deus*; CImp/1824 — “por Graça de Deos” e “em nome da Santíssima Trindade”.

70 Em momento posterior, cabe lembrar que a **EC n. 19/2000** à Constituição do Acre **acrescentou**, independentemente da decisão da Corte, a **expressão sob a proteção de Deus**. Vejamos: “A ASSEMBLEIA ESTADUAL CONSTITUINTE, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL, obedecendo ao ideário democrático, com o pensamento voltado para o POVO, inspirada nos HERÓIS DA REVOLUÇÃO ACREANA e **SOB A PROTEÇÃO DE DEUS**, promulga a seguinte CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE”.

71 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 7. ed., p. 27.

72 Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, 7. ed., p. 361-362 (grifamos).

73 Daniel Sarmiento, *Livres e iguais: estudos de direito constitucional*, p. 308.

74 Daniel Sarmiento, *Livres e iguais: estudos de direito constitucional*, p. 308.

75 Nesse sentido, de modo explícito, o art. 218 da Constituição de 1946: “Esta Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, depois de assinados pelos Deputados e Senadores presentes, serão **promulgados simultaneamente** pela Mesa da Assembleia Constituinte e entrarão em vigor na data da sua publicação”. O texto de 1988 também adotou essa técnica formal de promulgações e publicações autônomas.

76 Raul Machado Horta, *Direito constitucional*, 5. ed., p. 264.

77 Luís Roberto Barroso, Disposições constitucionais transitórias..., p. 491.

78 Raul Machado Horta, *Direito constitucional*, 5. ed., p. 261.

79 Isso não significa que não se possam encontrar referidas disposições transitórias, conforme se observou em algumas Constituições que implantaram as *Repúblicas Populares no Leste Europeu*, no segundo pós-guerra, como a da *Tchecoslováquia* de 1948 e a da *Iugoslávia* de 1946. Contudo, conforme alertou o autor, “as Constituições fundadoras de novo regime político e social, quando não dispensam a enunciação de disposições transitórias, **limitam-se a incluir nesse tópico regras de natureza técnica, regulando a composição de órgãos eletivos**” (op. cit., p. 261 e 263).

80 Raul Machado Horta, *Direito constitucional*, 5. ed., p. 262. Como **exemplos** de Constituições **sem disposições de transição**, podemos lembrar a norte-americana, algumas da França, da antiga União Soviética, as da China Popular, a Constituição da República Socialista de Cuba de 1976 etc. Segundo Pinto Ferreira, “... a Lei Maior norte-americana, por seu caráter sintético e lacônico, devia por brevidade eliminar o corpo das disposições transitórias, além de romper com o imperialismo britânico, que espoliava os colonos. As Constituições da França de 1793 e 1795 esfacelaram o antigo regime com os seus abusos e violências, estabelecendo uma nova ordem jurídico-política, assinalando a ascensão da burguesia como classe contra a nobreza. A Constituição russa de 1925 repudiou a ordem social burguesa, estabeleceu o regime da ditadura do proletariado, cortou as amarras com a tradição do capitalismo e do semifeudalismo ainda dominantes na Rússia czarista. Churchill chamou Lenin o *grande repudiador*, mas este suportou o peso do cerco capitalista e conseguiu fazer vitoriosa a revolução socialista. Mirkine-Guetzévitch, em sua *Teoria geral do Estado soviético*, chegou a dizer que o Estado soviético era um Estado sem direito, pois, ao seu sentir, eliminava a liberdade e a propriedade tradicionais, razão pela qual a Constituição, repudiando o passado, não cogitou de disposições transitórias” (*Curso de direito constitucional*, 10. ed., p. 576).

81 Pensamos que melhor teria sido a utilização da terminologia “disposição” em vez de “normas”.

82 Nesse sentido, de maneira interessante, conforme observam Souza Neto e Sarmiento, determinados institutos abrigados no ADCT podem ser considerados **cláusulas pétreas** “desde que estejam diretamente relacionados a algum outro limite material ao poder de reforma”, dando-se como exemplo o art. **68 do ADCT**, que reconhece, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, a

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos (Cláudio Pereira de Souza Neto, Daniel Sarmiento, *Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho*, p. 365, nota 29).

83 Luís Roberto Barroso, Disposições constitucionais transitórias..., p. 492.

84 **Art. 10, § 1.º, ADCT**: “Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7.º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias”.

85 **Art. 23, caput, ADCT**: “Até que se edite a regulamentação do art. 21, XVI, da Constituição, os atuais ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais”.

86 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 8. ed., p. 913-914.

87 **Art. 180 da Carta/37**: “Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União”.

88 Raul Machado Horta, *Direito constitucional*, 5. ed., p. 264.

89 Como exemplo, podemos citar o **art. 5.º do ADCT** ao determinar a não aplicação do disposto no art. 16 e das regras do art. 77 do corpo da Constituição às eleições previstas para 15.11.1988.

90 Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, 7. ed., p. 88.

- 1 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, 7. ed., p. 65 (original sem grifos).
- 2 Nesse sentido, Canotilho afirma que “poder constituinte significa, assim, **poder constituinte do povo**”, e que deve ser concebido “como uma ‘grandeza pluralística’ (Peter Häberle), ou seja, como uma pluralidade de forças culturais, sociais e políticas tais como partidos, grupos, igrejas, associações, personalidades, decisivamente influenciadoras da formação de ‘opiniões’, ‘vontades’, ‘correntes’ ou ‘sensibilidades’ políticas nos momentos preconstituintes e nos procedimentos constituintes” (op. cit., p. 75).
- 3 Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, p. 31.
- 4 *Poder constituinte e revolução: breve introdução à teoria sociológica do direito constitucional*, cap. IV, passim.
- 5 Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, p. 33.
- 6 M. G. Ferreira Filho, *O poder constituinte*, p. 58. O art. 28 da *Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão*, editada como preâmbulo da *Constituição francesa de 1793*, tem a seguinte redação: “Um povo tem, sempre, o direito de rever, de reformar e de mudar sua Constituição. Uma geração não pode sujeitar a suas leis as gerações futuras”. Para conhecimento desse e outros documentos, cf. importante trabalho de Fábio Konder Comparato, *A afirmação histórica dos direitos humanos*, passim.
- 7 **ADI 815** e expressão na **ADI 2.062**. Cf. nota de rodapé n. 13 (palavra “poder de fato” na tabela do item 4.5.1).
- 8 J. H. Meirelles Teixeira, *Curso de direito constitucional*, p. 213. Alerta-se o ilustre concurseiro de que essa nova ideia começa a aparecer nas provas de concurso (cf. questões).
- 9 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 81.
- 10 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 275 (original sem grifos). Essa interessante ideia de **insurreição**, a ser sancionada como **delito penal**, encontra fundamento no art. 5.º, XLIV, da CF/88: “constitui **crime inafiançável e imprescritível a ação** de grupos armados, civis ou militares, **contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**”.
- 11 Jorge Miranda, *Manual de direito constitucional*, 5. ed., t. II, p. 91-92 (igual ao original, que está sem grifos).

12 Vejamos as palavras de sua Excelência: “... Mas quero repetir principalmente que meu governo está ouvindo a voz democrática, as vozes democráticas que saem e emergem das ruas e que pedem mudanças. **É preciso saber escutar a voz das ruas**. Só ela é capaz de nos impulsionar a andar ainda mais rápido. É preciso que todos, todos mesmo, sem exceção, entendam esses sinais com humildade e acerto. Isso vale não apenas para nós, líderes de governos, mas igualmente para os brasileiros e brasileiras que estão em suas casas e também para aqueles que foram às ruas. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer mais rápido muita coisa”. E, nesse sentido, afirma: “Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um **plebiscito popular** que autorize o funcionamento de um **processo constituinte específico** para fazer a **reforma política** que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar e já deixou claro que não quer ficar parado onde está” (cf. a íntegra do discurso da Sra. Dilma Rousseff: <<http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-reuniao-com-governadores-e-prefeitos-de-capitais>> — inclusive com acesso ao vídeo — acesso em 10.01.2014).

13 O Min. Ayres Britto, no julgamento da **ADI 2.356-MC** (25.11.2010), utilizou como sinônimo de “**poder de fato**” a expressão “**poder suprapositivo**”, que não deve ser confundida, em outro contexto (e os dois sentidos já foram perguntados em concursos públicos), com “**princípios de direito suprapositivo**” (**ADI 815**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 28.03.1996), que significou “**princípios de direito natural**”. Nesses termos, o Min. Celso de Mello utilizou a expressão “**direito suprapositivo**” não positivado, ou seja, “**direito natural**, consubstanciado em ‘princípios naturais e critérios isonômicos, gerais e coletivos da lei de um estado democrático’” (**ADI 2.062**, j. 11.03.2004).

14 Isso porque, como já apontamos, a produção da normatividade em questão dá-se não pela emanção direta da soberania popular (o que se verifica no originário), mas por sua manifestação indireta. Michel Temer observa: “parece-nos mais convincente a expressão ‘Poder Constituinte’ para o caso de emanção normativa *direta* da soberania popular. O mais é fixação de *competências*: a *reformatora* (capaz de modificar a Constituição); a *ordinária* (capaz de editar a normatividade infraconstitucional)” (*Elementos de direito constitucional*, p. 35).

15 Leda P. Mota e Celso Spitzcovsky, *Curso de direito constitucional*, p. 2, justificando: “Em outro dizer, tendo em vista que a ordem jurídica começa com a Constituição, o Poder que a elabora, logicamente, não pode ser jurídico”.

- 16 Sobre o tema dos **limites ao poder de reforma**, cf. *item 9.14.1*.
- 17 Celso Bastos, ao tratar do poder constituinte estadual, observa que sua manifestação é tida, normalmente, por constituinte. “Contudo, as diferenças que apresenta com o poder constituinte nacional são de tal monta que parece impróprio conservar-se o mesmo nome para realidades tão díspares. O único ponto comum entre o poder constituinte nacional e o chamado poder constituinte estadual é que ambos se reúnem para elaborar uma Constituição. Tudo o mais são diferenças.” Entre elas, o autor observa que “o poder constituinte originário, o que elabora a Constituição Federal, é soberano, enquanto o poder constituinte estadual é autônomo. O primeiro não está subordinado a nenhuma limitação jurídica. O segundo atua dentro de uma área de competência, delimitada pela Constituição Federal” (*Curso de direito constitucional*, p. 306).
- 18 *Poder constituinte dos Estados-membros*, p. 19.
- 19 Op. cit., p. 95. Anna Cândida observa que o **poder constituinte de revisão estadual** pode ser **normal** ou **extraordinário (anômalo)**. Será *normal* quando “previsto na própria Constituição estadual” e “exercido nos moldes e para os fins nela apontados”, dentro dos condicionamentos nela estabelecidos e, também, observando os limites da Constituição Federal. Será *extraordinário* (ou *anômalo*), quando a reforma (revisão) estadual for impulsionada por uma reforma na Constituição Federal. E conclui: “a fonte ou o fundamento do *poder de revisão normal* é a Constituição estadual; o *poder de revisão extraordinário* tem duplo fundamento: de um lado, a Constituição Federal ou o Constituinte Originário — fundamento primário — e de outro a Constituição Estadual — fonte secundária” (op. cit., p. 99).
- 20 *Constituição Federal anotada*, p. 506-509, *passim*.
- 21 Nesse sentido, destacamos interessante precedente em relação à **iniciativa reservada de projeto de lei** pelo Chefe do Poder Executivo estadual (aplicando-se, simetricamente, o art. 61, § 1.º, I e II, da CF/88 — cf. *item 9.13.3.3*): “A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno — art. 25, *caput* —, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. Precedentes” (**ADI 1.594**, Rel. Min. Eros Grau, j. 04.06.2008, Plenário, *DJE* de 22.08.2008).
- 22 Trata-se da Lei Orgânica do Distrito Federal, de 08.06.1993, publicada no *DODF*, de 09.06.1993, cujos arts. 1.º e 2.º, corroborando o preceituado na Lei Maior, prescrevem que

o DF, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, **observados os princípios constitucionais**, reger-se-á pela referida Lei Orgânica e integrará a união indissolúvel da República Federativa do Brasil (cf.: <<http://www.cl.df.gov.br>>).

23 À época, chegamos a escrever: “o critério por nós escolhido é o **jurídico-formal**, no sentido de que só os *Estados-membros* elaboram suas Constituições através da manifestação do poder constituinte derivado decorrente. *Distrito Federal* e *Municípios* regem-se por **lei orgânica**, que nada tem de parecido (do ponto de vista **formal**) com a Constituição de um Estado (Federal ou Federado)”. Contudo, conforme esclarecemos acima, **mudamos de opinião**. Encontramos determinada prova do CESPE/UnB na linha do que sustentávamos (*vide* questão ao final desse capítulo — *Magistratura/TRF1/2009*), mas deixando claro que se tratava do critério **jurídico-formal**.

24 Nesse sentido, cf. José Adércio Leite Sampaio, *A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional*, p. 568, nota 9.

25 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 13-14.

26 Noemia Porto, *Temas relevantes de direito constitucional* — poder constituinte, p. 54-55 (original sem grifos).

27 Este, inclusive, parece-nos ser o entendimento de Ivo Gabriel ao longo de sua obra *Constituição estadual*, especialmente p. 112-114, ao conceituar poder constituinte decorrente.

28 Segundo anota Bulos, lembrando Georges Burdeau (*Traité de science politique*, v. 4, p. 247, 290 e s.), “é chamado de **difuso** porque não vem formalizado nas constituições. Mesmo assim, está presente na vida dos ordenamentos jurídicos” (*Curso de direito constitucional*, p. 316).

29 Nesse sentido, aceitando a ideia de **poder constituinte difuso**, cf. José Afonso da Silva, *Poder constituinte e poder popular*, p. 285. **Por outro lado**, muito embora reconheçam que as Constituições não estão (nem devem estar) imunes ao tempo, caracterizando-se como “verdadeiros organismos vivos” (*living Constitution*), “com condições de se adaptarem às mudanças no ambiente que as circundam”, Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento alertam: “sem embargo, não se deve levar ao extremo a possibilidade de

mutação constitucional, concebendo-a como o resultado do exercício de uma espécie de *poder constituinte difuso*, como chegou a preconizar Georges Burdeau, sobretudo num contexto, como o brasileiro, em que as alterações formais na Constituição não são tão difíceis” (*Direito constitucional*, p. 342).

30 Cf. Georges Burdeau, *Traité de science politique*, 1969, v. 4, p. 246-247. Em tradução livre apresentada por Barroso, escreveu **Burdeau**: “se o poder constituinte é um poder que faz ou transforma as Constituições, deve-se admitir que sua atuação não se limita às modalidades juridicamente disciplinadas de seu exercício. (...) Há um exercício quotidiano do poder constituinte que, embora não esteja previsto pelos mecanismos constitucionais ou pelos sismógrafos das revoluções, nem por isso é menos real. (...) Parece-me, de todo modo, que a ciência política deva mencionar a existência desse **poder constituinte difuso**, que não é consagrado em nenhum procedimento, mas sem o qual, no entanto, a Constituição oficial e visível não teria outro sabor que o dos registros de arquivo” (Luís Roberto Barroso, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 128, nota 15).

31 Anna Cândida da Cunha Ferraz, *Processos informais de mudança da constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais*, p. 10 (original sem grifos).

32 Luís Roberto Barroso, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 128.

33 Gilmar F. Mendes, Inocêncio M. Coelho, Paulo G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 220.

34 Walter Claudius Rothenburg prefere denominá-lo **transnacional**: “sem abdicar do Estado nacional e, portanto, a partir, mas além, do Estado nacional” (*Direito constitucional*, p. 76, nota 190).

35 Kildare Gonçalves Carvalho, *Direito constitucional*, 13. ed., p. 277.

36 Maurício A. Rodrigues, *Poder constituinte supranacional: esse novo personagem*, p. 96, apud Kildare G. C., *Direito constitucional*, p. 276-277.

37 M. Neves, *Transconstitucionalismo*, *passim*.

38 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 81.

39 C. P. de Souza Neto, Daniel Sarmento, *Direito constitucional*, p. 277-278.

40 Carlyle Popp, A retroatividade das normas constitucionais e os efeitos da Constituição Federal sobre os direitos adquiridos, *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 29, n. 113, p. 87-88, jan./mar. 1992.

- 41 *Comentários à Constituição de 1967*, com a EC n. 1, de 1969.
- 42 Estudaremos melhor esse tema ao tratar do “controle de constitucionalidade” no item 6.7.2.
- 43 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 283.
- 44 Muito embora existam decisões em sentido contrário (RE 353.508-AgR, 2.^a T., j. 15.05.2007), destacamos entendimento mais atual admitindo a **modulação** dos efeitos da decisão de não recepção, adotado em controle difuso (não encontramos exemplos em ADPF. Cf. *itens* 6.7.1.2.9 e 13.6.3 — *jurisprudência pendente de sedimentação*): “O art. 142, § 3.º, inciso X, da Constituição da República é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980. O **princípio da segurança jurídica** impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, **modulem-se os efeitos da não recepção**: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011” (RE 600.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.02.2011, Plenário, DJE de 1.º.07.2011, com repercussão geral).
- 45 Fernanda Dias Menezes de Almeida e Anna Cândida da Cunha Ferraz, Efeitos da Constituição sobre o direito anterior, *RPGESP*, p. 47, jun. 1989.
- 46 Efeitos da Constituição sobre o direito anterior, p. 48.
- 47 “Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda n. 1, de 1969, e pelas posteriores. § 1.º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, III, e 159, I, c, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III”.
- 48 *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 221.

49 Alertamos que o STF, no julgamento da questão de ordem no Inq. 687, em 25.08.1999, **cancelou a Súmula 394**. Cf. esse assunto e a discussão sobre a prerrogativa de foro no *item 9.9.2.3*.

50 Em outro caso, o STF entendeu, afastando o art. 5.º, XXXVI, que “... normas de ordem pública que instituem novo padrão monetário têm aplicação imediata em relação aos contratos em curso como forma de reequilibrar a relação jurídica antes estabelecida” (cf. RE 164.836, Rel. Min. Nelson Jobim, *DJ* de 02.06.2006; RE 136.901, *DJ* de 02.06.2006; RE 167.987, *DJ* de 02.06.2006; RE 170.484, *DJ* de 02.06.2006).

51 Cf. a novidade trazida pela EC n. 45/2004 ao introduzir o § 3.º ao art. 5.º.

- 1 *Elementos de direito constitucional*, p. 23.
- 2 O Professor José Afonso da Silva, do Largo São Francisco (USP), o grande responsável pelo estudo da matéria, tratou do tema de maneira sistemática na primeira edição, em 1967, de *Aplicabilidade das normas constitucionais*. O trabalho foi escrito para servir de tese ao concurso para provimento da Cátedra de Direito Constitucional na FADUSP, que se realizou em agosto de 1969. Valemo-nos, a seguir, de sua sistematização para apresentar a matéria, na medida em que é a sua teoria que vem sendo perguntada nos concursos, tendo, inclusive, o STF adotado o critério classificatório do autor, conforme RT 723/231. Não podemos deixar de mencionar a crítica feita 37 anos depois por Virgílio Afonso da Silva, em tese pela qual conquistou o cargo de Professor Titular de Direito Constitucional da FADUSP: cf. *O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais*, especialmente o cap. 6.
- 3 *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 262. Em outro momento, o mestre do Largo São Francisco, valendo-se da lição de J. H. Meirelles Teixeira, já havia definido as normas constitucionais de eficácia plena como “aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular” (ibidem, p. 101).
- 4 Em **nosso entendimento**, a norma contida no art. 5.º, VII (“é **assegurada**, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”) tem **eficácia contida**, e não limitada. Isso porque, ao se estabelecer que a prestação está “**assegurada**”, o direito já se tornou exigível. O que a lei pode fazer é, eventualmente, prescrever os seus termos, reduzindo a sua abrangência. Conforme anotou José Afonso da Silva, “...o **direito é constitucional**. Vem da Constituição, não da lei. ‘Nos termos da lei’ não significa que esta é que vai outorgar o direito. Significa apenas que o direito constitucionalmente conferido **pode** ser regulado por lei, que esta **pode** definir certos critérios, certas exigências, tendo em vista a natureza da entidade de internação coletiva, mormente quando esta seja militar ou mantida pelo Estado Brasileiro” (*Comentário contextual à Constituição*, 8. ed., p. 97). **CUIDADO:** devemos alertar, contudo, muito embora esse nosso entendimento, que o **CESPE/UnB**, na **prova da Polícia Federal de 2014** (*conhecimentos básicos, nível superior*), considerou referido dispositivo como norma de **eficácia limitada**. Essa é, então, para as provas preambulares, a orientação quando a banca examinadora for o CESPE/UnB. De fato, uma classificação

ou outra vai depender da maneira como se encarar o preceito estabelecido na Constituição. Seguindo o nosso entendimento (eficácia contida), destacamos, também, a posição de Uadi Lammêgo Bulos, na edição de **2015** do seu *Curso de direito constitucional* (p. 482). Lembramos que o direito à assistência religiosa já está regulamentado em algumas leis, o que, muito provavelmente, não ensejará uma discussão mais ampla sobre a eficácia no STF (por esse motivo — divergência doutrinária —, não achamos adequada a cobrança desse entendimento em provas preambulares). Para conhecimento, destacamos os atos normativos em questão: **a)** Lei n. 6.923/81, alterada pela Lei n. 7.672/88, para as Forças Armadas; **b)** art. 41, VII, da Lei n. 7.210/84 (LEP) — estabelecimentos prisionais; **c)** art. 124, XIV, da Lei n. 8.069/90 (ECA) — direito do adolescente privado de liberdade; **d)** Lei n. 9.982/2000 — dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares.

5 Segundo José Afonso da Silva, *necessidade ou utilidade pública, interesse social ou econômico e perigo público iminente* “são outros tantos conceitos que interferem com a eficácia de determinadas normas constitucionais. Com base neles o Poder Público pode limitar situações subjetivas, circunscrevendo a autonomia de sujeitos privados, especialmente em relação ao direito de propriedade. O inciso XXII do art. 5.º garante o direito de propriedade, mas os incisos XXIV e XXV oferecem os elementos de suas limitações, permitindo sua desapropriação por *necessidade ou utilidade pública* ou por *interesse social*, bem como seu uso pela autoridade competente no caso de *perigo público iminente*” (*Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 113).

6 José Afonso da Silva ensina: “normas de eficácia contida, portanto, são aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais nelas enunciados” (*Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 116).

7 Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, p. 24.

8 Art. 4.º da EC n. 47/2005: “Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do *caput* do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional n. 41, de 2003”.

- 9 Cf. *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 164.
- 10 *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 262.
- 11 José Afonso diz: “São, pois, normas constitucionais de princípio institutivo aquelas através das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei” (*Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 126).
- 12 Normas programáticas são aquelas “através das quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado” (*Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 138).
- 13 Cf. *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 147-148.
- 14 Cf. **Súmula 648/STF, 24.09.2003**: “a norma do § 3.º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”, e os seguintes precedentes: ADI 4, *RTJ* 147/719; RE 157897, *RTJ* 151/635; RE 184837; RE 186594; RE 237472; RE 237952; AI 187925 AgR. Ainda, cf. **SV 7/2008-STF**.
- 15 Nesse sentido, retomando a explicação do Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro (SS 1.583-AM/STF), cf. posicionamento do STF, manifestado por 7 votos a 4 na 3.ª Sessão Administrativa, realizada em 24 de junho de 1998 (*Inf. 217/STF* e AO 524/PA, 14.02.2001).
- 16 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, 18. ed., p. 312 e 582.
- 17 *Norma constitucional e seus efeitos*, p. 101-115.
- 18 *Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 48 e s.
- 19 *Constituição Federal anotada*, p. 335.
- 20 *Comentário contextual à Constituição*, p. 408.
- 21 *Comentário contextual à Constituição*, p. 408.
- 22 *Comentário contextual à Constituição*, p. 409.
- 23 Nesse sentido, após **reiteradas decisões** sobre essa matéria constitucional (cf., por exemplo, MI 721, MI 795, MI 788, MI 925, MI 1.328, MI 1.527, MI 2.120, MI 1.785, MI

4.158 AgR-segundo, MI 1.596 AgR, MI 3.215 AgR-segundo), o **STF** aprovou a *PSV n. 45* e, assim, editou, em 09.04.2014, a **SV n. 33**, com o seguinte teor: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4.º, inciso III da Constituição Federal, **até a edição de lei complementar específica**” (*DJE* de 24.04.2014).

24 *Norma constitucional e seus efeitos*, p. 115.

- 1 Todo o conteúdo desse *item 6.1* foi retirado, com algumas adaptações, de Pedro Lenza, *Coisa julgada erga omnes: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante* (originalmente defendido como tese de doutorado — USP).
- 2 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 47 e 49.
- 3 A. Buzaid, *Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*, p. 21.
- 4 Cf. Rui Barbosa, *Actos inconstitucionais do congresso e do executivo ante a justiça federal*, p. 41 e s.
- 5 A. Buzaid, *Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*, *passim*.
- 6 J. de C. Nunes, *Teoria e prática do poder judiciário*, p. 588-589.
- 7 F. Campos, *Direito constitucional*, v. 1, p. 430-431.
- 8 M. Cappelletti, *O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado*, p. 115-116.
- 9 Hans Kelsen, *Teoria pura do direito*, p. 374-376.
- 10 Conforme anotou Elival da Silva Ramos, “a dificuldade de Kelsen em admitir o ato legislativo inexistente, assim como o inválido sancionado com a nulidade *ab initio*, está ligada a seus pressupostos teóricos, segundo os quais o Direito é concebido como uma construção lógica impecável, em que os elementos inferiores não podem estar em contradição com os superiores, sob pena de serem proscritos do mundo jurídico. Daí a pretensão de reduzir as categorias da inexistência e da nulidade à da anulabilidade, trabalhando com a ideia de uma validade transitória, até a desconstituição do ato por decisão judicial” (*A inconstitucionalidade das leis: vício e sanção*, p. 23). Cf. H. Kelsen, *Teoria pura do direito*, p. 292-300.
- 11 M. Cappelletti, *O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado*, p. 116. Esse prazo, segundo anota Gilmar Mendes, é de **18 meses**, nos termos do art. 140, § 5.º, terceiro período, da Constituição austríaca (I. G. da S. Martins, G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10.11.99*, p. 426).
- 12 F. C. Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1946*, t. 6, p. 413 e s.

- 13 R. M. M. N. Ferrari, *Efeitos da declaração de inconstitucionalidade*, 5. ed., p. 268-296.
- 14 M. Cappelletti, *O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado*, p. 120-124.
- 15 R. M. M. N. Ferrari, *Efeitos da declaração de inconstitucionalidade*, 5. ed., p. 164-176, esp. p. 168; 172-173 e 176.
- 16 Cf. Willoughby, *The constitutional law*, v. 1, p. 9-10, e, também, Thomas M. Cooley, *Treaties on the constitutional limitations*, 1878, p. 227, apud I. G. da S. Martins, G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868*, de 10.11.99, p. 452.
- 17 I. G. da S. Martins, G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 421-425.
- 18 I. G. da S. Martins, G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 423.
- 19 Gilmar Mendes transcreve parte da justificativa da Suprema Corte dos Estados Unidos: “... uma vez aceita a premissa de que não somos requeridos e nem proibidos de aplicar uma decisão retroativamente, devemos então sopesar os méritos e deméritos em cada caso, analisando o histórico anterior da norma em questão, seu objetivo e efeito, e se a operação retrospectiva irá adiantar ou retardar sua operação. Acreditamos que essa abordagem é particularmente correta com referência às proibições da 4.^a Emenda, no que concerne às buscas e apreensões desarrazoadas. Ao invés de ‘depreciar’ a Emenda devemos aplicar a sabedoria do Justice Holmes que dizia que ‘na vida da lei não existe lógica: o que há é a experiência’ (*United States Reports*, 381:629)” (*Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 424).
- 20 S. R. de Barros, O nó górdio do sistema misto, in A. R. Tavares, W. C. Rothenburg (org.), *Arguição de descumprimento de preceito fundamental: análise à luz da Lei n. 9.882/99*, p. 191 — no caso, referindo-se ao sistema brasileiro. Nessa linha da flexibilização, Palu, ao tratar dos **graus de retroatividade das sentenças de inconstitucionalidade**, observa que “... a doutrina e jurisprudência norte-americanas têm as respostas nas técnicas, v.g., da *prospective overruling* e *limited retrospectivity*; justamente no país que estabeleceu a regra da nulidade absoluta da lei inconstitucional e da eficácia *ex tunc* dos julgamentos vem agora a técnica, sobretudo da *limited prospectivity*, a dispor que a sentença é aplicável somente aos processos iniciados após a decisão,

inclusive afetando o processo que originou a questão; já a *prospectivity overruling*, ou *pure prospectivity*, exclui toda a retroatividade, não se aplicando ao processo de origem. Evidentemente, em um sistema que depende dos casos concretos (*cases*) para a declaração de inconstitucionalidade, a técnica da *pure prospectivity* gerou perplexidades, ainda que a declaração possa valer para casos concretos futuros” (Osvaldo Luiz Palu. *Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos*, p. 173).

21 E. G. de Enterría, *Justicia constitucional: la doctrina prospectiva en la declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales*, *RDP* 92/5.

22 Cf. G. F. Mendes, *Tribunal Constitucional alemão. O apelo ao legislador — “appellentscheidung” — na práxis da corte constitucional alemã*, *RDP* 99/32-53.

23 No Brasil, veja o precedente da **ADI 526**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *RTJ* 145/101.

24 I. G. da S. Martins, G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 431-447.

25 C. A. L. Bittencourt, *O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis*, p. 148.

26 Cf. **RE 197.917/SP** — Rel. Min. Mauricio Corrêa, j. 06.06.2002, Pleno; DJ de 07.05.2004, p. 8 (“EMENTA: ... 8. Efeitos. Princípio da **segurança jurídica**. Situação excepcional em que a declaração de “nulidade, com seus normais efeitos *ex tunc*, resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do **interesse público** para assegurar, em caráter de exceção, efeitos *pro futuro* à declaração incidental de inconstitucionalidade”). Cf., ainda, trazendo vários exemplos de “modulação de efeitos da decisão”, a **densidade** do voto do Min. Gilmar Mendes.

2727 Todo este *item 6.2* foi apresentado em outro trabalho nosso: “A arguição de descumprimento de preceito fundamental sob a perspectiva do STF”, in *Aspectos atuais do controle de constitucionalidade no Brasil: recurso extraordinário e a arguição de descumprimento de preceito fundamental*, São Paulo: Forense, 2003 (coord.: André Ramos Tavares e Walter Claudius Rothenburg), p. 192-197.

28 Para análise dos sistemas norte-americano, austríaco e alemão, cf. Gilmar Ferreira Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 1-18. Para estudo comparado e histórico do controle da constitucionalidade, interessante o trabalho de Oscar Vilhena Vieira: *Supremo Tribunal Federal*, p. 39-96 e de Ivo Dantas, *O valor da Constituição*, passim. Importante, também, dentre tantos outros trabalhos da doutrina nacional, notadamente em relação ao traçado da evolução do sistema de controle de

constitucionalidade do direito pátrio, a contribuição de Gilmar Ferreira Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 18-65; Clèmerson Merlin Clève (*A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 45-73) e Regina Maria Macedo Nery Ferrari (*Efeitos da declaração de inconstitucionalidade*, p. 24-48).

29 C. M. Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 63-64.

30 Convém observar, contudo, que, antes mesmo da promulgação da Constituição de 1891, o art. 58, § 1.º, “a” e “b”, da Constituição provisória de 1890 (Dec. n. 510, de 22.06.1890) e o Decreto n. 848, de 11.10.1890, já estabeleciam regras de controle difuso inspiradas no *judicial review* do direito norte-americano. Posteriormente, a Lei federal n. 221, de 20.11.1894, abordou, com clareza, o modelo, nos termos do art. 13, § 10: “os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição”. Por fim, cabe salientar, de modo amplo, a manutenção das regras sobre o **controle jurisdicional difuso** pela reforma constitucional de 1926.

31 G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*, p. 24.

32 Nos termos do parágrafo único do art. 96 da Constituição de 1937, “no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, **a juízo do Presidente da República**, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, **poderá** o Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, **ficará sem efeito a decisão do Tribunal**”.

33 Os arts. 1.º a 3.º da aludida Emenda Constitucional explicitam a amplitude da convocação da Assembleia Nacional Constituinte: “Art. 1.º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1.º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional”; “Art. 2.º O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do seu Presidente”; “Art. 3.º A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta dos Membros da Assembleia Nacional Constituinte”.

34 Sobre a **ADC**, cf. importante trabalho doutrinário e prático (votos da ADC 1-1/DF), coordenado por Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes, intitulado *Ação*

declaratória de constitucionalidade, passim.

35 J. A. Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 554-555.

36 Conforme analisaremos no item 6.7.1.3, esse conceito deve ser ampliado diante do conceito de **bloco de constitucionalidade**, por meio do qual o parâmetro é constituído não só pela Constituição escrita e posta, como também pelas leis com valor constitucional formal (emendas à Constituição e, nos termos do art. 5.º, § 3.º (EC n. 45/2004), os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros); pelo conjunto de preceitos e princípios decorrentes da Constituição, inclusive implícitos (não escritos) e, ainda, ampliativamente, segundo alguns, pelos princípios integrantes daquilo que a doutrina vem chamando de “ordem constitucional global”. Essa última perspectiva, contudo, que abarcaria os valores suprapositivos, não vem sendo aceita como parâmetro de constitucionalidade para o direito brasileiro.

37 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 982.

38 Depois de muito pensar e discutir, falar em vício de ética, vício de consentimento, a colega **Simone Aparecida Smaniotto** sugeriu “vício de decoro parlamentar”, o que entendemos perfeito, tendo em vista a regra do art. 55, § 1.º.

39 Cf. L. A. D. Araujo e V. S. Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 24.

40 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 959.

41 Ao tratar do *processo legislativo*, veremos que o processo de formação da lei compreende uma **fase inicial**, em que é deflagrado o referido procedimento, e outras duas fases, a **constitutiva** (deliberação parlamentar e executiva) e a **complementar** (promulgação e publicação), chamadas acima de fases posteriores à de iniciativa.

42 Para análise do tema da iniciativa “privativa” (reservada ou exclusiva), cf. item 9.13.3.3.

43 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 1321.

44 Idem, *ibidem*.

45 Clèmerson Merlin Clève, *Fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, 2. ed., p. 41.

46 Luís Roberto Barroso, *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*, 2. ed., p. 29.

- 47 Cf. L. A. D. Araujo e V. S. Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 24.
- 48 A **AP 470**, sem dúvida, pode ser considerada o **maior e mais complexo julgamento da história do STF**, iniciado em 02.08.2012 e concluído em 17.12.2012, tomando praticamente toda a pauta do segundo semestre de 2012. Com 38 réus, os autos somaram 234 volumes, 495 apensos e um total de 50.199 páginas. Foram 53 sessões de julgamento e horas de trabalho. O acórdão foi publicado no *DJE* de 22.04.2013, com surpreendentes **8.405 páginas**. O STF julgou, ainda, embargos de declaração e infringentes interpostos.
- 49 *Elementos de direito constitucional*, p. 43.
- 50 Resolução n. 93, de 1970, devidamente consolidada (Regimento Interno) em relação ao texto editado no final da 49.^a (quadragésima nona) Legislatura, nos termos do Ato da Mesa do Senado Federal n. 1, de 1999, em cumprimento ao disposto no art. 402 regimental.
- 51 Aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, e alterado pelas Resoluções ns. 1, 3 e 10, de 1991; 22 e 24, de 1992; 25, 37 e 38, de 1993; 57 e 58, de 1994; 1, 77, 78 e 80, de 1995; 5, 8 e 15, de 1996; 33, de 1999; 11 e 16, de 2000; 19, 21 e 25, de 2001; 28, de 2002; 15, de 2003; 20, 22 e 23, de 2004; 30 e 34, de 2005; e 45 e 50, de 2006.
- 52 No mesmo sentido o *Inf. 30/STF*: “Por maioria de votos, o Tribunal conheceu em parte de mandado de segurança impetrado por Deputados Federais contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados que determinara o processamento de proposta de emenda constitucional em alegada violação a normas do Regimento Interno daquela casa legislativa e ao art. 60, § 5.º, da CF (‘A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.’). Reconhecendo a existência, em tese, de **direito subjetivo dos impetrantes-parlamentares a não serem compelidos a participar de processo legislativo que se tenha por contrário à Constituição**, o Tribunal afastou a preliminar de carência de ação suscitada nas informações da autoridade apontada como coatora. Prevaleceu, de outra parte, o entendimento de que **as questões regimentais levantadas pelos impetrantes estariam imunes ao controle judicial, por estarem compreendidas, em princípio, no conceito de interna corporis**. Contra: os votos dos Ministros Marco Aurélio, Ilmar Galvão e Celso de Mello — que dele conheciam integralmente —, e dos Ministros Carlos Velloso e Octavio Gallotti — que dele não conheciam —, o mandado de segurança foi conhecido em parte, nos limites do fundamento constitucional. Precedentes citados: MS 20257 (RTJ 99/1031); MS 21754

(AgRg) (Pleno, 7.10.93); MS 21648 (Pleno, 5.5.93); MS 22183 (Pleno, 5.4.95). **MS 22.503-DF**, Rel. orig. Min. Marco Aurélio; Rel. p/ ac. Min. Maurício Corrêa, 8.5.96”.

53 Nessa perspectiva restritiva em relação ao controle judicial, cf. decisão do Ministro Barroso, negando liminar em MS preventivo impetrado por parlamentares com o objetivo de obstar a tramitação de PEC que passaria a exigir a aprovação do Congresso Nacional para a demarcação de terras indígenas, sob o argumento de violação de cláusula pétrea (**MS 32.262**, j. 13.09.2013, *Inf. 721/STF — pendente de julgamento*). Em suas palavras, “a Constituição atribuiu ao Congresso Nacional a incumbência de servir como o espaço público de vocalização de ideias, opiniões e interesses de todos os segmentos da sociedade. Somente por **exceção extrema** se deve obstar a discussão de um assunto de interesse público. Tal como compreendido atualmente, o ideal de governo democrático é o *deliberativo*, em que a ênfase recai sobre a capacidade de cidadãos, livres e iguais, decidirem seu futuro em um processo argumentativo honesto, em que prevaleça a força das melhores razões. Embora a deliberação não se restrinja (nem deva se restringir) aos órgãos formais de representação política, é inegável sua importância nesse cenário” (fls. 13 de sua decisão, *item 22*).

54 Cf. a íntegra da medida liminar em **Inf. 483/STF**, tendo sido a decisão publicada no *DJU* de 16.10.2007. Em **27.09.2012**, foi julgado **prejudicado** o pedido do referido MS, por perda de objeto (art. 21, IX, do *RISTF*). Apenas para conhecimento, o PGR manifestou-se pela denegação da ordem no sentido de que “... as questões referentes exclusivamente à interpretação e à aplicação dos regimentos internos das casas legislativas constituem matéria *interna corporis*, da alçada exclusiva da respectiva casa, sendo, portanto, imunes ao controle judicial, em homenagem ao princípio da separação dos poderes”, **não admitindo**, portanto, a proposta inaugurada pelo Min. Gilmar Mendes das **normas constitucionais interpostas**.

55 Novamente, para efeito de concursos, adotar o entendimento do citado parecer do MPF no sentido de **impossibilidade de apreciação das matérias *interna corporis*, sob pena de se violar o princípio da separação de poderes**. Alertamos, contudo, que o conceito de “**normas constitucionais interpostas**” já foi perguntado em concursos públicos.

56 Nesse sentido, Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, p. 41; Celso Bastos, *Curso de direito constitucional*, p. 397; Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, t. 1, p. 90; e Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, 9. ed., p. 562. José Afonso da Silva, de maneira mais abrangente, observa que “o controle

político é o que entrega a verificação da inconstitucionalidade a órgãos de natureza política, tais como: o próprio *Poder Legislativo*, solução predominante na Europa no século passado; ou um órgão especial, como o *Presidium do Soviete Supremo*, da ex-União Soviética (Constituição da URSS, art. 121, n. 4) e o *Conseil Constitutionnel* da vigente Constituição francesa de 1958 (arts. 56 a 63)” (*Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 51).

57 Luís Roberto Barroso, *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*, 2. ed., p. 42-43.

58 Alfredo Buzaid, em lapidar lição, já dizia, em 1958, que o controle de constitucionalidade no Brasil era exercido em duas modalidades: “a) pelo controle difuso, no processo comum, quando a parte alega, como fundamento da ação ou da defesa, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo: esta arguição é feita *incidenter tantum* e constitui sempre *questão prejudicial*; b) pelo sistema concentrado, por meio de ação direta, intentada pelos legitimados pela Constituição, em que o objetivo próprio do processo é a declaração da inconstitucionalidade” (apud Ada Pellegrini Grinover, *Controle de constitucionalidade*, *Revista de Processo*, 90/11).

59 “EMENTA: É constitucional decreto de chefe de poder executivo estadual que determina aos órgãos a ele subordinados que se abstenham da prática de atos que impliquem a execução de dispositivos legais vetados por falta de iniciativa exclusiva do poder executivo. Constitucionalidade do Decreto n. 7.864, de 30 de abril de 1976, do Governador do Estado de São Paulo. Representação julgada improcedente” (**Rp 980/SP**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 21.11.1979, Pleno, *DJ* de 19.09.1980, p. 7202, *RTJ* 96-03/496). Nesse mesmo sentido, ainda: “O Poder Executivo não é obrigado a cumprir leis que considere inconstitucionais” (**Recurso de MS 13.950**, j. 10.10.1968, Min. Amaral Santos, *RDA* 97/116).

60 Zeno Veloso, *Controle jurisdicional de constitucionalidade*, 2. ed., p. 317 e s.

61 Nesse sentido, cf. L. R. Barroso, *O controle...*, 2. ed., p. 71; Clèmerson Merlin Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, 2. ed., p. 247-248; e Gustavo Binenbojm, *A nova jurisdição constitucional brasileira*, p. 216 e s.

62 Conforme anotou o Min. Gilmar Mendes, a evolução do sistema de controle de constitucionalidade “está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da Súmula 347 em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988” (cf. **MS 25.888-MC**, j. 22.03.2006 — *matéria pendente*).

- 63 Uadi Lammêgo Bulos, *Constituição Federal anotada*, 4. ed., p. 815.
- 64 A questão está para ser definida no julgamento do **RE 441.280**, afetado ao Pleno (*matéria pendente*).
- 65 José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 12. ed., v. 5, p. 30.
- 66 John Marshall, *Decisões constitucionais de Marshall*, p. 22 (texto adaptado para o português moderno).
- 67 Idem, p. 29.
- 68 Oscar Vilhena Vieira, *Supremo Tribunal Federal*, 2. ed., p. 66.
- 69 Nos termos do art. 93, XI, da CF/88, na redação dada pela EC n. 45/2004, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído **órgão especial**, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, **provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno**.
- 70 *Direito constitucional*, v. 2, p. 417, item n. 140.
- 71 Como vimos acima, a regra geral é a do art. 97 da CF/88. Confira a ementa: “Controle difuso de constitucionalidade de norma jurídica. Art. 97 da Constituição Federal. — A declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica *incidenter tantum*, e, portanto, por meio do **controle difuso de constitucionalidade**, é o pressuposto para o Juiz, ou o Tribunal, no **caso concreto**, afastar a aplicação da norma tida como inconstitucional. Por isso, não se pode pretender, como o faz o acórdão recorrido, que não há declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica *incidenter tantum* quando o acórdão não a declara inconstitucional, mas afasta a sua aplicação, porque tida como inconstitucional. Ora, em se tratando de inconstitucionalidade de norma jurídica a ser declarada em **controle difuso por Tribunal**, só pode declará-la, em face do disposto no artigo 97 da Constituição, o **Plenário dele ou seu Órgão Especial**, onde este houver, pelo voto da **maioria absoluta** dos membros de um ou de outro. No caso, não se observou esse dispositivo constitucional. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 179.170/CE, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 30.10.1998, p. 15, *Ement.* v. 01929-03, p. 450, j. 09.06.1998 — Primeira Turma).
- 72 Lúcio Bitencourt, *O controle jurisdicional de constitucionalidade das leis*, p. 43-46.

73 Nesse mesmo sentido, a 2.^a Turma do STF também se manifestou, em acórdão proferido no Ag. 168.149 (Ag. Rg.), Rel. Min. Marco Aurélio, *RTJ* 162/765: “EMENTA: *Inconstitucionalidade — Incidente — Deslocamento do processo para o Órgão Especial ou para o Pleno — Desnecessidade*. Versando a controvérsia sobre **ato normativo já declarado inconstitucional pelo guardião maior da Carta Política da República** — o Supremo Tribunal Federal — descabe o deslocamento previsto no artigo 97 do referido Diploma maior. O julgamento de plano pelo órgão fracionado homenageia não só a **racionalidade**, como também implica **interpretação teleológica do artigo 97** em comento, evitando a burocratização dos atos judiciais no que **nefasta ao princípio da economia e da celeridade. A razão de ser do preceito está na necessidade de evitar-se que órgãos fracionados apreciem, pela vez primeira, a pecha de inconstitucionalidade arguida em relação a um certo ato normativo**” (original sem grifos).

74 “EMENTA: *Processo civil. Controle difuso da constitucionalidade. Princípio da reserva de plenário*. O juiz singular pode deixar de aplicar lei inconstitucional; os órgãos fracionários dos tribunais, não — porque, mesmo no âmbito do controle difuso da constitucionalidade, os tribunais só podem deixar de aplicar a lei pelo seu plenário ou, se for o caso, pelo respectivo órgão especial (CF, art. 97), observado o procedimento previsto no artigo 480 e seguintes do Código de Processo Civil, salvo se já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (CPC/73, art. 481, parágrafo único). Recurso especial conhecido e provido” (REsp 89.297/MG (1996/0012088-9), *DJ* de 07.02.2000, p. 151, Rel. Min. Ari Pargendler, 3.^a Turma do STJ — no mesmo sentido, cf. AG 353.520, Min. Gilson Dipp; *DJ* de 16.02.2001, 5.^a Turma do STJ).

75 Nesse sentido, firme a jurisprudência do STF: “vê-se, portanto, na linha de iterativa jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte e em outros tribunais, que a incompatibilidade entre uma lei anterior (como a norma ora questionada inscrita na Lei 691/1984 do Município do Rio de Janeiro/RJ, p. ex.) e uma Constituição posterior (como a Constituição de 1988) resolve-se pela constatação de que se registrou, em tal situação, revogação pura e simples da espécie normativa hierarquicamente inferior (o ato legislativo, no caso), **não se verificando, por isso mesmo, hipótese de inconstitucionalidade**. Isso significa que a discussão em torno da incidência, ou não, do postulado da recepção — precisamente por não envolver qualquer juízo de inconstitucionalidade (mas, sim, quando for o caso, o de simples revogação de diploma pré-constitucional) — **dispensa**, por tal

motivo, **a aplicação do princípio da reserva de Plenário** (CF, art. 97), legitimando, por isso mesmo, a possibilidade de reconhecimento, por órgão fracionário do Tribunal, de que determinado ato estatal não foi recebido pela nova ordem constitucional (*RTJ* 191/329-330), além de inviabilizar, porque incabível, a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata (*RTJ* 95/980; *RTJ* 95/993; *RTJ* 99/544; *RTJ* 143/355; *RTJ* 145/339, v.g.)” (**AI 582.280 AgR**, voto do Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2006, 2.^a T. No mesmo sentido: **AI 669.872-AgR**, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.12.2012, 1.^a T., *DJE* de 14.02.2013; **RE 495.370-AgR**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.08.2010, 2.^a T.).

76 “Alegação de violação da Súmula Vinculante 10. (...) Decisões reiteradas desta Corte têm respaldado a prerrogativa de conferir determinada interpretação à lei como atributo inerente à própria atividade jurisdicional, o que, em consequência, afasta a equiparação proposta pela parte vencida entre as hipóteses de interpretação desfavorável a seus interesses e de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo analisado” (**Rcl 12.107-AgR**, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.06.2012, Plenário, *DJE* de 1.º.08.2012. Cf., ainda, **RE 184.093**, Moreira Alves, *DJ* de 05.09.1997, **RE 460.971** e **ARE 676.006-AgR**).

77 “Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF. (...) Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CR” (**Rcl 10.864-AgR**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.2011, Plenário, *DJE* de 13.04.2011).

78 Em sentido parecido, destacamos, também da 2.^a T.: “**não há reserva de Plenário** (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno **ou** por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, **não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade**. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam **equivalentes**. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão” (**AI 607.616-AgR**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 31.08.2010, 2.^a T., *DJE* de 1.º.10.2010).

79 O art. 143, *caput*, do *RISTF* estabelece que o Plenário se reunirá com a presença mínima de 6 Ministros, sendo dirigido pelo Presidente do Tribunal. O parágrafo único do

referido artigo acrescenta que o *quorum* para a **votação de matéria constitucional** e para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, dos membros do Conselho Nacional da Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral é de **8 Ministros**. Temos, então, um *quorum* regimental superior de instalação da sessão de julgamento de 8 Ministros, ao passo que a lei será declarada inconstitucional, pela maioria absoluta, conforme o art. 97 (lembre-se de que o STF é composto de **11 Ministros**).

80 Nesse sentido, Pontes de Miranda observa que “a Constituição não distingue, aí, leis ou outros atos (dos poderes públicos) *federais ou estaduais*, territoriais, distritais ou municipais. Os pressupostos são apenas o de se tratar de regra jurídica e o de haver o Supremo Tribunal Federal julgado, por decisão definitiva, inconstitucional” (*Comentários à Constituição de 1946*, v. II, p. 284). Para se ter um exemplo de suspensão de lei estadual, cf. a **RSF 12/2006**, que suspende a execução da Lei estadual n. 11.564, de 18 de agosto de 1998, do Estado de Pernambuco, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos de Ação Originária n. 864-6 — Pernambuco. Para um exemplo de suspensão de lei municipal, cf. **RSF 13/2006**, que suspende a execução do art. 7.º, I e II, e do art. 27 da Lei municipal n. 6.989, de 29 de dezembro de 1966, do Município de São Paulo, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 210.586-4/São Paulo.

81 Lembramos que a **EC n. 45/2004**, nos termos de seu art. 4.º, extinguiu os Tribunais de Alçada existentes. Sobre o assunto, cf. análise no *item 11.15*.

82 *Elementos de direito constitucional*, p. 44.

83 Esse entendimento é **majoritário**, destacando-se, conforme levantamento feito por Clèmerson Merlin Clève, a doutrina de Themístocles Cavalcanti, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, José

Afonso da Silva, Nagib Slaibi Filho, Anna Cândida da Cunha Ferraz e Regina Macedo Nery Ferrari (C. M. Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 122). Confira, também, Ada Pellegrini Grinover (Controle da constitucionalidade, *RePro* 90/12). No mesmo sentido, apesar de não declarar expressamente o seu entendimento, parece ser a posição de Alfredo Buzaid (*Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*, p. 88-90). Em sentido contrário, entendendo o efeito **ex tunc**, cf. Clèmerson Merlin Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 122-125, que,

após interessante compilação, na mesma linha de seu entendimento, destaca Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Napoleão Nogueira da Silva e Marcelo Caetano.

- 84 Nesse sentido, cf. Clèmerson Merlin Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 94. Celso de Mello, em obra teórica, escreveu: “O Senado exaure a sua competência constitucional no momento em que promulga e edita a resolução suspensiva. Não pode, ao depois, a pretexto de melhor interpretar a decisão judicial proferida pelo STF, modificar-lhe o sentido ou restringir-lhe os efeitos. Nesse sentido: *RTJ*, 38:5, 38:569, 39:628” (*Constituição federal anotada*, p. 139-140).
- 85 Todo o conteúdo deste título foi retirado, com algumas adaptações, de Pedro Lenza, *Coisa julgada erga omnes: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante* (no prelo, originalmente defendido como tese de doutorado — USP).
- 86 A. Buzaid, *Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*, p. 23-24.
- 87 A. P. Grinover, Controle da constitucionalidade, *RePro* 90/11. Nesse sentido, cf. Rui Barbosa, *Actos inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal*, p. 99.
- 88 **RE 197.917/SP**, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, Pleno, *DJ* de 07.05.2004, p. 8.
- 89 **HC 82.959/SP**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.02.2006, Plenário, *DJ* de 1.º.09.2006 (para aprofundamento do tema, cf. *item 14.10.28.1*).
- 90 Interessantíssima a análise de Zavascki, pedindo-se vênia para transcrever parte de seu voto que, como será visto, coincide com o seu entendimento doutrinário sobre a matéria: **REsp 828.106/SP**, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1.ª Turma, j. 02.05.2006, *DJ* de 15.05.2006, p. 186: “(...) 6. A inconstitucionalidade é vício que acarreta a nulidade *ex tunc* do ato normativo, que, por isso mesmo, é desprovido de aptidão para incidir eficazmente sobre os fatos jurídicos desde então verificados, situação que não pode deixar de ser considerada. Também não pode ser desconsiderada a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade. **Embora tomada em controle difuso, é decisão de incontestável e natural vocação expansiva, com eficácia imediatamente vinculante para os demais tribunais, inclusive o STJ** (CPC/73, art. 481, § único: ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de

inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’), e com força de inibir a execução de sentenças judiciais contrárias, que se tornam inexigíveis (CPC/73, art. 741, § único; art. 475-L, § 1.º, redação da Lei 11.232/05...). Sob esse enfoque, **há idêntica força de autoridade nas decisões do STF em ação direta quanto nas proferidas em via recursal**. Merece aplausos essa **aproximação**, cada vez mais evidente, do **sistema de controle difuso de constitucionalidade ao do concentrado**, que se generaliza também em outros países (SOTELO, José Luiz Vasquez. *A jurisprudência vinculante na ‘common law’ e na ‘civil law’*, *Temas atuais de direito processual ibero-americano*, Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 374; SEGADO, Francisco Fernandez. *La obsolescencia de la bipolaridad ‘modelo americano-modelo europeo kelseniano’ como criterio analítico del control de constitucionalidad y la búsqueda de una nueva tipología explicativa*, apud Parlamento y Constitución, Universidad de Castilla-La Mancha, Anuario (separata), n. 6, p. 1-53). No atual estágio de nossa legislação... **é inevitável que se passe a atribuir simples efeito de publicidade às resoluções do Senado previstas no art. 52, X, da Constituição**. É o que defende, em doutrina, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes...”.

91 G. F. Mendes, O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso clássico de mutação constitucional, *RIL*, 162/165.

92 T. A. Zavaski, *Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional*, p. 135-136.

93 C. A. L. Bittencourt, *O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis*, p. 134.

94 Lenio L. Streck, Hermenêutica e princípios da interpretação constitucional, in: J. J. Gomes Canotilho, Gilmar F. Mendes, Ingo W. Salet, Lenio L. Streck, *Comentários à Constituição do Brasil*, p. 82. Para o aprofundamento desse tema, remetemos o nosso leitor para o item 6.6.5.2 deste estudo.

95 Referido voto pode ser encontrado em *Notícias/STF*, 29.08.2005 — 16h46.

96 Em outra passagem: “Torna-se relevante salientar, na linha do que destacou o eminente Ministro *Gilmar Mendes*, que esta **Suprema Corte deu efeito transcendente aos próprios motivos determinantes que deram suporte ao julgamento plenário do RE 197.917/SP**. Esse aspecto assume relevo indiscutível, pois permite examinar a presente controvérsia constitucional em face do denominado **efeito transcendente dos motivos determinantes subjacentes à decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida no julgamento plenário do RE 197.917/SP**, Rel.

Min. *Maurício Corrêa*, especialmente em decorrência das intervenções dos eminentes Ministros *Nelson Jobim*, *Gilmar Mendes* e *Sepúlveda Pertence*. Cabe referir, em particular, neste ponto, a intervenção do eminente Ministro *Gilmar Mendes*, que ressaltou a **aplicabilidade, ao E. Tribunal Superior Eleitoral, do efeito vinculante emergente da própria ‘ratio decidendi’ que motivou o julgamento do precedente mencionado**” (ADIs 3.345 e 3.365).

97 Em suas palavras, “... teriam razão os ilustres autores (referindo-se a Lúcio Bittencourt e Castro Nunes) se, no litígio constitucional, o objeto do processo fosse a lei em si, não o direito subjetivo da parte; nestas condições, a coisa julgada, transcendendo os limites da demanda, abrangeria a todos. Mas enquanto os juízes resolvem *in casu* o direito particular, ameaçado ou violado por ato ilegal da legislatura ou do executivo, os efeitos do julgado valem *inter partes*, não se estendendo *erga omnes*”. A única maneira de se estender os efeitos da decisão *erga omnes* seria mediante **resolução do Senado Federal**, que suspenderia a execução da lei, cassando, em definitivo, a sua **eficácia** (A. Buzaid, *Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*, p. 87-88).

98 Outro tema a merecer a edição de súmula vinculante seria a declaração incidental, com efeito *ex nunc*, da inconstitucionalidade da regra fixada pela Lei n. 11.464/2007 ao art. 2.º, § 1.º, da Lei de Crimes Hediondos, que determina a obrigatoriedade de cumprimento de pena **inicialmente** em regime fechado, mesmo quando a pena for inferior a 8 anos (**HC 111.840 e Rcl 15.626** — cf. *item 14.10.28.1*).

99 Lenio Luiz Streck, Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?, *Revista Consultor Jurídico*, 18.12.2014, p. 7.

100 Lenio Luiz Streck, Por que agora dá para apostar no projeto do novo CPC!, *Revista Consultor Jurídico*, 21.10.2013, p. 2.

101 Lenio Luiz Streck, *idem*.

102 Lenio Luiz Streck, *idem*.

103 **Art. 102, § 2.º, CF/88**: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas **ações diretas de inconstitucionalidade** e nas **ações declaratórias de constitucionalidade** produzirão **eficácia contra todos** e **efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

104 **Art. 103-A, CF/88**: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,

mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.

105 Lenio Luiz Streck, Comentário ao artigo 926. In: Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (coords.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo, Saraiva, 2015 (no prelo, gentilmente cedido pelo autor).

106 Art. 6.º, § 2.º, da Res. n. 1/2002-CN: “... a Comissão Mista, se for o caso, proferirá, pelo Relator ou Relator Revisor designados, o parecer no Plenário da Câmara dos Deputados, podendo estes, se necessário, solicitar para isso prazo até a sessão ordinária seguinte”.

107 Art. 27 da Lei n. 9.868/99: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de **dois terços** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

108 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, p. 569-570.

109 Como se sabe, a **Res. n. 230/2002** do STF dispõe sobre as **siglas** dos registros processuais no âmbito da Suprema Corte. Assim, para referida ação, a sigla que vem sendo utilizada é, indistintamente, **IF**, ou seja, **Intervenção Federal**. Entendemos, contudo, que o STF deverá adequar à nomenclatura fixada no art. 36, III, da CF/88, e na Lei n. 12.562/2011, qual seja, **representação interventiva** e, assim, propomos a utilização da sigla **RI**.

110 Ada Pellegrini Grinover, *Controle da constitucionalidade*, p. 12.

111 Conforme advertem David Araujo e Serrano Nunes, “nem toda resolução ou decreto legislativo podem ser objeto de controle concentrado, já que podem não constituir atos normativos. Por exemplo, a resolução que autoriza o processo contra o Presidente da República, prevista no inciso I do art. 51 da Constituição, não está revestida de **abstração e generalidade**, o que impede o seu controle. Da mesma forma, a autorização para que o Presidente da República se ausente do País por mais de quinze dias, prevista no art. 49, III, não tem qualquer **generalidade e abstração**, constituindo, portanto, **ato concreto e**

impossível de ser controlado pelo controle concentrado” (*Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 42).

112 *Direito constitucional*, p. 559.

113 *Idem*, *ibidem*, p. 558.

114 Cf. posicionamento de Clèmerson Merlin Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 146.

115 “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a **excepcionalidade** por

escrito, sob pena de **responsabilidade** disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado” (Sessão Plenária de 13.08.2008).

116 “Emenda Constitucional emanada de Constituinte derivado pode ser declarada inconstitucional pelo STF, cuja função precípua é de guardião da CF” — ADI 939, *RTJ* 151/755 — cf. anotações ao Regimento Interno do STF, disponível em: <<http://www.stf.jus.br>> (ícone *legislação — regimento interno atual*).

117 *RTJ* 131/954 — cf. anotações ao Regimento Interno do STF, disponível em: <<http://www.stf.jus.br>> (ícone *legislação — regimento interno atual*).

118 Conferir análise da utilização de medida provisória em matéria orçamentária no *item 9.14.4.7*.

119 Medida Cautelar em ADI 129, j. 28.08.1992.

120 *Direito constitucional*, p. 564, referindo-se à *RTJ* 142/718.

121 Mesmo antes da **EC n. 45/2004** entendíamos que os tratados internacionais veiculadores de direitos humanos fundamentais ingressavam no ordenamento interno, por força do art. 5.º, § 2.º, da CF/88, com o caráter de norma constitucional, enquanto outros tratados internacionais, de natureza diversa, com o caráter de norma infraconstitucional. Sobre nossa posição, consultar Pedro Lenza, *As garantias processuais dos tratados internacionais sobre direitos fundamentais*, *Revista de Processo*, São Paulo, n. 92, p. 199-216, out./dez. 1998; também *O direito e os desafios da contemporaneidade*.

122 Dentre tantos julgados indicadores dessa primeira análise (que será superada), cf.: *RTJ* 149/479; *RTJ* 136/230; *RTJ* 135/111; *RTJ* 121/270; *RTJ* 84/724; *RTJ* 82/129; *RT* 739/290;

RT 733/254; RT 727/102; RT 724/330; HC 68.582; HC 69.254; RTJ 141/570; HC 72.131; HC 70.625; HC 72.366; HC 70.338; HC 71.159; HC 71.933; HC 71.739; HC 72.171; HC 72.621; HC 75.512-7/SP; HC 75.362-1/PR, STF. Cf., ainda, *Inf. 48/STF* e o precedente da ADI 1.480-DF (RTJ 174/335-336, Rel. Min. Celso de Mello).

123 Cf. *Inf. 531/STF*, assim como **RE 349.703** e, no julgamento do **HC 87.585**, o **cancelamento** da **S. 619/STF** (“A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito”).

124 Araujo e Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, cit., p. 34.

125 No caso, interessante a leitura do *leading case*: **ADI 815**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 28.03.1996, Plenário, *DJ* de 10.05.1996. **Guerreiros concurreiros**, vamos em frente, muita determinação para a prova oral!

126 Para uma perspectiva teórica inicial, cf. Otto Bachof, *Normas constitucionais inconstitucionais?*, passim.

127 RTJ 133/8 e questão de ordem na ADI 612, j. 03.06.1993, *DJ* de 06.05.1994, disponível em: <<http://www.stf.jus.br>> (ícone *legislação — regimento interno atual*).

128 Estudamos melhor esse tema quando tratamos do poder constituinte.

129 Cf. ADI 2.980, Rel. p/ o ac. Min. Cezar Peluso, j. 05.02.2009, Plenário, *DJE* de 07.08.2009. No mesmo sentido: ADI 2.549, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1.º.06.2011, Plenário; ADI 4.041-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.03.2011, Plenário; ADI 2.333-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.11.2004, Plenário.

130 Entendemos que se a alteração foi meramente formal (como renumeração de artigos), sem modificação de conteúdo, não haveria prejudicialidade. Naturalmente, por se tratar de novo ato normativo, deveria haver aditamento da petição inicial (**ADI 246**, j. 16.12.2004).

131 Cf.: RTJ 152/731-732, Rel. Min. Celso de Mello; RTJ 153/13, Rel. Min. Moreira Alves; RTJ 154/396, Rel. Min. Celso de Mello; RTJ 154/401, Rel. Min. Paulo Brossard; RTJ 160/145, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 117/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 437/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *DJU* de 17.08.1994; ADI 519/DF, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 747/TO, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 2.263/SE, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 3.032-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 04.03.2004, p. 50; ADI 1.468-4/DF, j. 30.11.2004 etc.

132 ADI (QO-QO) 1.244-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 23.04.2003 (*Inf.* 305/STF) (**matéria pendente de julgamento**). O candidato deverá acompanhar essa ADI, já que poderá haver mudança de entendimento do STF. Concordamos com a nova linha que se vislumbra. Entendemos interessante expor esse posicionamento em fase escrita e oral, o que mostrará bastante conhecimento à banca examinadora! Para aprofundamento, nessa linha, cf., também, o voto do Min. Gilmar Mendes na ADI 4.426. **Sucesso!**

133 Nesse sentido: “a revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes”. (**ADI 1.445-QO**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.11.2004, Plenário, *DJ* de 29.04.2005.) No mesmo sentido: ADI 1.298 e ADI 1.378, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.10.2010, Plenário, *DJE* de 09.02.2011; ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, j. 07.02.1992, Plenário, *DJ* de 24.06.1994.

134 “Ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada em prol da Resolução n. 7/2005, do CNJ. Medida cautelar. (...) A Resolução n. 7/2005 do CNJ reveste-se dos atributos da **generalidade** (os dispositivos dela constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas), **impessoalidade** (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e **abstratividade** (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos). A Resolução 7/2005 se dota, ainda, de caráter **normativo primário**, dado que arranca diretamente do § 4.º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade” (**ADC 12-MC**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 16.02.2006, Plenário, *DJ* de 1.º.09.2006). Em relação à Res. n. 175/2013, cf. **MS 32.077**, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013.

135 Em relação à expressão “bloco de constitucionalidade”, cf. Louis Favoreu, Francisco Rubio Llorente, *El bloque de la constitucionalidad*: simposium franco-español de derecho constitucional, p. 19-21 e s. No direito brasileiro, indispensável a leitura do trabalho de Juliano Taveira Bernardes, *Controle abstrato de constitucionalidade*: elementos materiais e princípios processuais, p. 124-162.

- 136 Juliano Taveira Bernardes, *Controle abstrato de constitucionalidade*, p. 134. No voto proferido na *ADI 595-ES (Inf. 258/STF)*, o Ministro Celso de Mello, muito embora indique a tendência reducionista, não nos parece ter fechado as portas para a perspectiva ampliativa de “bloco de constitucionalidade” (“ordem constitucional global”). *Esse tema parece ser muito interessante para a fase escrita ou oral!*
- 137 Sobre essa nova sistemática, cf. *item 9.14.5.2.2*. Em relação à ampliação da noção de “bloco de constitucionalidade” com a **Reforma do Judiciário**, cf. José Carlos Francisco, Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados internacionais, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 99.
- 138 Cf. William Burnham, *Introduction to the law and the legal system of the United States*, p. 66-67. Aliás, para os que se interessarem por algum conhecimento do **sistema norte-americano**, vale a pena a leitura do referido trabalho que tem sido utilizado por muitos alunos estrangeiros que cursam o programa de **LL.M (Master of Laws)** nos EUA.
- 139 Sobre o assunto, cf. Pedro Lenza, *Coisa julgada erga omnes: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante* (no prelo).
- 140 Sobre o assunto, cf. *ADI 2.729/RN*, Rel. Min. Eros Grau, 16.11.2005 (*Inf. 409/STF*); *ADI 2.797/DF* e *ADI 2.860/DF*, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 15.09.2005 (*Inf. 401/STF*); *RTJ 189/469-470*, Rel. Min. Maurício Corrêa; *ADI 2.728/AM*, Rel. Min. Maurício Corrêa; *ADI 2.982-QO/CE*, Rel. Min. Gilmar Mendes.
- 141 “Por entender caracterizada a ofensa ao art. 22, XX, da CF, que confere à União a competência privativa para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.343/2003 e, por **arrastamento**, do Decreto 24.446/2002, ambos do Estado de Pernambuco, que dispõem sobre o serviço de loterias no âmbito da referida unidade federativa” (*Inf. 452/STF*).
- 142 Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, *Controle de constitucionalidade*, p. 188.
- 143 Nesse sentido, observa Canotilho que, em relação ao controle de constitucionalidade em abstrato, “(...) podem existir **‘inconstitucionalidades consequenciais** ou por **arrastamento**’ justificadas pela conexão ou interdependência de certos preceitos com os preceitos especificamente impugnados (...)” (J. J. Gomes Canotilho, *Direito*

constitucional, 5. ed., item n. 3, p. 1046-1047). Cf., ainda, Jorge Miranda, *Manual de direito constitucional*, 2. ed., Coimbra, 1987, t. 2, p. 297, item n. 73/VI, e Clèmerson Merlin Clève, *A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro*, 2. ed., p. 56 — “a inconstitucionalidade **antecedente** ou **imediata** decorre da violação, direta e imediata, de uma norma constitucional por uma lei ou ato normativo. A inconstitucionalidade **consequente** ou **derivada** decorre de um efeito reflexo da inconstitucionalidade antecedente ou imediata” (grifamos).

144 Em relação ao rito específico dos Juizados, confira regras apresentadas no *item* 12.6.7.6.

145 Cf. *RTJ* 178/423, Rel. Min. Moreira Alves; RE 196.857-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 208.798/SP, Rel. Min. Sydney Sanches; RE 229.810/SP, Rel. Min. Néri da Silveira; RE 295.740/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Recomendamos a leitura do interessante voto do Ministro Celso de Mello, que bem resume a matéria: **AI 339.696/SP**, *DJ* de 12.08.2005, p. 53.

146 Ana Paula de Barcellos, *Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional*, p. 231-232.

147 Cf. Pedro Lenza, *Coisa julgada erga omnes*: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante (originalmente defendido como tese de doutorado — USP).

148 **Art. 18, § 4.º**: “a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por **lei estadual**, dentro do **período determinado por lei complementar federal**, e dependerão de **consulta prévia**, mediante plebiscito, às populações dos **Municípios envolvidos**, após divulgação dos **Estudos de Viabilidade Municipal**, apresentados e publicados na forma da lei” (redação dada pela EC n. 15, de 1996). Cf., ainda, **EC n. 57/2008**.

149 Esse entendimento, mesmo diante de flagrante violação ao art. 18, § 4.º, foi tomado na **ADI 3.316/MT** contra a Lei n. 6.983/98, do Estado do Mato Grosso, que cria o Município de Santo Antônio do Leste, a partir de área desmembrada do Município de Novo São Joaquim, e na **ADI 3.489/SC** contra a Lei n. 12.294/2002, do Estado de Santa Catarina, que anexa ao Município de Monte Carlo a localidade Vila Arlete, desmembrada do Município de Campos Novos (cf. *Inf. 427/STF*).

150 Esquematização elaborada com base no voto do Ministro Eros Grau.

151 Quanto à necessidade de **lei complementar federal** fixando o período para a criação de novos Municípios, cf. ADI 2.381-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.06.2001, *DJ* de 14.12.2001; ADI 2.967, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.02.2004, *DJ* de 19.03.2004; ADI 3.013, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 12.05.2004, *DJ* de 04.06.2004. Sobre a indispensabilidade do *plebiscito às populações diretamente interessadas*, cf. ADI 2.812, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 09.10.2003; ADI 2.702, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 05.11.2003, e ADI 2.632-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 29.08.2003.

152 O STF, no julgamento da ADI 2.395, que discutia a constitucionalidade da redação conferida ao art. 18, § 4.º, pela EC n. 15/96, adotou “... a orientação fixada pela Corte no julgamento da **ADI 2.381/RS** (*DJU*, 14.12.2001), em que se declarou a constitucionalidade da EC 15/96, afastando-se a alegada ofensa ao princípio federativo (CF, art. 60, § 4.º, I). Asseverou-se que a EC 15/96 foi elaborada com o escopo de acabar com a crescente proliferação de municípios verificada no período pós-88, com base na redação originária do art. 18, § 4.º, da CF, que criava condições propícias para que os Estados desencadeassem o processo de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios por leis próprias, respeitados parâmetros mínimos definidos em lei complementar, também estadual. Vencido o Min. Marco Aurélio que, por vislumbrar ofensa ao art. 60, § 4.º, I, da CF, julgava procedente o pedido” (ADI 2.395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 09.05.2007, *Inf.* 466/STF).

153 “CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE — ARTIGO 3.º, § 1.º, DA LEI N. 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 — EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro **não contempla a figura da constitucionalidade superveniente**. TRIBUTÁRIO — INSTITUTOS — EXPRESSÕES E VOCÁBULOS — SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL — PIS — RECEITA BRUTA — NOÇÃO — INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1.º DO ARTIGO 3.º DA LEI N. 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1.º do artigo 3.º da Lei n. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a

totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada” (RE 390.840, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.11.2005, DJ de 15.08.2006).

154 ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22.03.2006, DJ de 10.08.2006.

155 O art. 1.026 do CPC/2015, reafirmando que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, inova e explicita ao afirmar que **não possuem efeito suspensivo**.

156 Devemos deixar claro que o entendimento que vem sendo exposto neste item deve ser observado **apenas** em relação às **ações objetivas do controle de constitucionalidade**. Para as outras ações, sejam recursais ou originárias, o STF não tem aplicado esse entendimento da publicação da ata, mas o da publicação do acórdão. Vejamos um exemplo: “Recursos interpostos antes da publicação do **acórdão recorrido** são intempestivos (AI 375.124-AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello). Entendimento quebrantado, tão somente, naquelas hipóteses em que a decisão recorrida já está materializada nos autos do processo quando da interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente (AI 497.477-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso). O que não é o caso dos autos” (Inq. 2.630-ED, Rel. Min. Ayres Britto, j. 26.03.2009, DJE de 15.05.2009).

157 Destacamos: “A obrigatoriedade de observância da decisão de liminar, em controle abstrato realizado pelo STF, impõe-se com a publicação da **ata** da sessão de julgamento no Diário da Justiça. O ajuizamento de reclamação **independe tanto da publicação do acórdão cuja autoridade se quer garantir** (ADC 4-MC) **como de sua juntada**” (Rcl 1.190-AgR e Rcl 1.197-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, j. 08.09.2005, Plenário, DJ de 03.02.2006. No mesmo sentido: Rcl 3.113-AgR, j. 18.08.2010; Rcl 6.167-AgR, j. 18.09.2008; Rcl 5.537-AgR, j. 29.10.2007; Rcl 4.857-AgR, j. 29.03.2007; Rcl 3.632-AgR, j. 02.02.2006).

158 Observe-se, apenas, que, conforme apontou o Ministro Moreira Alves, na hipótese de tramitação simultânea de ações, uma buscando declarar a inconstitucionalidade de **lei estadual** perante o STF (confrontação da lei estadual perante a CF) e outra perante o TJ local (confrontação da lei estadual perante a CE), tratando-se de norma repetida da CF na CE, **suspende-se o curso da ação proposta no TJ local até julgamento final da ação intentada no STF** (STF, Pleno, ADI 1.423/SP, DJ 1, de 22.11.1996, p. 45684).

159 *Curso de direito constitucional*, p. 32.

160 Nesse sentido, **S. 642/STF, 24.09.2003**: “não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal”.

161 Registro do Acórdão n. 111.897, data de julgamento: 1.º.09.1998; órgão julgador: Conselho Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJ* de 02.06.1999, p. 14.

162 M. C. de Almeida Neto, *O novo controle de constitucionalidade municipal*, p. 143.

163 A. R. Tavares, *Curso de direito constitucional*, 8. ed., p. 476.

164 A legitimação é apenas para a Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados (art. 57, § 4.º). **A Mesa do Congresso Nacional (art. 57, § 5.º) não tem legitimidade para a propositura da ADI.**

165 O STF já admitia, antes da EC n. 45/2004 e da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, a propositura pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

166 O STF já admitia, antes da EC n. 45/2004 e da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, a propositura pelo Governador do Distrito Federal. Deixamos claro que a legitimação foi estabelecida para o **Chefe do Poder Executivo Estadual** e/ou **Distrital** e não para o ente federativo. Assim, muito embora a ação possa ser proposta pelo Governador do Estado-Membro, o ente federativo em si, no caso, o Estado-Membro, não está autorizado a recorrer, já que não foi incluído no rol (**taxativo**) dos legitimados. A legitimação recursal nas ações de controle concentrado deve ser paralela à legitimidade processual ativa para recorrer. Vejamos: “Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por governador de Estado. Decisão que não a admite, por incabível. Recurso de agravo interposto pelo próprio Estado-membro. **Ilegitimidade recursal** dessa pessoa política. Inaplicabilidade, ao processo de controle normativo abstrato, do art. 188 do CPC/73. Recurso de agravo não conhecido. O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer em sede de controle normativo abstrato. O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer contra as decisões proferidas pelo relator da causa (Lei 9.868/1999, art. 4.º, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra aquelas emanadas do próprio Plenário do STF (Lei 9.868/1999, art. 26)” (ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, Plenário, *DJ* de 14.12.2001. No mesmo sentido: ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.04.2013, Plenário, *DJE* de 05.08.2013).

167 Decidiu o STF que a exigência de representação do partido político no Congresso Nacional é preenchida com a existência de apenas um parlamentar, em qualquer das Casas Legislativas. A representação do partido político na ação dar-se-á pelo **Diretório Nacional** ou pela **Executiva do Partido**, de acordo com a sua constituição, não admitindo a legitimidade ativa ao Diretório Regional ou Executiva Regional, na medida em que **não podem agir nacionalmente** (STF, ADI 1.449-8/AL, Rel. Min. Ilmar Galvão, *DJ* 1, de 21.05.1996, p. 16877). O STF entendeu a possibilidade de outorga do instrumento de mandato pelo Presidente do Partido (ADI 2.552, j. 27.11.2001, fazendo-se referência à ADI 2.187-QO). De acordo com a jurisprudência do STF, a aferição da representação do partido político em uma das Casas do Congresso Nacional (sendo suficiente em apenas uma), dá-se no momento da propositura da ação (ADI 2.054-QO).

168 Em relação às **confederações sindicais**, o STF já decidiu que deverão preencher os requisitos da legislação pertinente, entre os quais o de serem constituídas por, no mínimo, **3 federações sindicais**, nos termos do art. 535 da CLT (ADI 1.121/RS, Rel. Min. Celso de Mello, sessão plenária de 06.09.1995 — *Inf. 5/STF*). Como exemplo, citamos a Confederação Nacional de Saúde (CNS), a Confederação Nacional do Comércio (CNC) etc., todas devendo demonstrar pertinência temática.

169 Devemos alertar que, em se tratando de **entidades sindicais**, o STF **não reconhece a legitimação ativa** dos **sindicatos** e das **federações**, ainda que possuam abrangência nacional, em razão de sua menor hierarquia. Da mesma forma, o STF **não reconhece a legitimação** das **centrais sindicais**. Para se ter um precedente, destacamos o caso concreto da **CUT**, que, segundo a Corte, não se enquadra na primeira parte do inciso IX do art. 103 da Constituição, não, tendo, portanto, legitimação ativa (**ADI 271-MC**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24.09.1992, Plenário, *DJ* de 06.09.2001. No mesmo sentido: **ADI 1.442**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.11.2004, Plenário). Essa jurisprudência foi **confirmada** mesmo após a alteração da CLT pela **Lei n. 11.468/2008**, que definiu as centrais sindicais como entidades de representação geral dos trabalhadores, constituídas em âmbito nacional: “EMENTA: (...). 2. Muito embora ocorrido o reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei n. 11.648/2008, **a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical**. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadoras dos interesses gerais dos trabalhadores, e **permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada categoria profissional ou econômica**. 3. A fórmula

alternativa prevista no art. 103, IX, do Texto Magno, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação” (**ADI 4.224-AgR**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1.º.08.2011, Plenário).

170 Classe (“entidade de classe”) deve ser entendida como **categoria profissional**. Nesse sentido, o STF negou legitimidade à União Nacional dos Estudantes (UNE), por entender tratar-se de **classe estudantil**, e não de **classe profissional** (STF, ADI 89-3/DF, Rel. Min. Néri da Silveira). Ainda, o STF vem exigindo que a entidade de classe preencha o requisito da **homogeneidade** (cf. ADI 386). Em outro julgado, estabeleceu o STF: “A heterogeneidade da composição da autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: Precedentes do STF” (**ADI 3.381**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.06.2007, Plenário. No mesmo sentido: **ADI 3.805-AgR**, Rel. Min. Eros Grau, j. 22.04.2009, Plenário). Em relação à necessidade de preenchimento do requisito da **homogeneidade**, destacamos ação proposta pela *UNIDAS — União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde* que é integrada por pessoas vinculadas a **categorias distintas**. No caso, conforme definiu o STF, “os associados da requerente estão **unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico** (prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento caracteriza a **unidade de propósito na representação associativa**, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação” (**ADI 4.701**, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.08.2014, Plenário, *DJE* de 25.08.2014).

171 De acordo com a jurisprudência do STF, **entidade de classe de âmbito nacional**, aplicando analogicamente a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (art. 7.º, da Lei n. 9.096/95), é aquela de atuação transregional e organizada em pelo menos **9 Estados da Federação** (ou seja, em ao menos 1/3 dos 27 entes federativos — 26 Estados e o DF. Cf., também, medida liminar na ADI 386). Dessa forma, não basta a simples declaração formal constante de seus atos constitutivos. **CUIDADO:** neste último precedente, o Ministro Moreira Alves ressaltou que referido critério de organização “cederá nos casos em que haja comprovação de que a categoria dos associados só existe em menos de 9 Estados”. Assim, em outro julgado, resgatando a aludida ressalva, em situação concreta que envolvia a *Associação Brasileira dos Extratores e Refinadores de Sal (ABERSAL)*, o STF afastou a exigência da organização em pelo menos 1/3 dos Estados da Federação. Vejamos: “EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação

Brasileira dos Extratores e Refinadores de Sal — ABERSAL contra a Lei Estadual n. 8.299/2003, do Estado do Rio Grande do Norte, que ‘dispõe sobre formas de escoamento do sal marinho produzido no Rio Grande do Norte e dá outras providências’. 2. Legitimidade ativa. 3. Inaplicabilidade, no caso, do critério adotado para a definição do caráter nacional dos partidos políticos (Lei n. 9.096/95: art. 7.º), haja vista a **relevância nacional da atividade dos associados** da ABERSAL, não obstante a produção de sal ocorrer em poucas unidades da federação” (**ADI 2.866-MC**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.09.2003). Finalmente, também alterando entendimento, o STF passou a admitir ajuizamento de ADI por **“associação de associação”** (cf. análise neste item e, ainda, ADI 3.153 AgR/DF — *Inf. 361/STF*).

172 Conforme anotou o Min. Celso de Mello em seu voto na ADI 271-MC, as **confederações sindicais** (que têm legitimação ativa e estão abarcadas pelo art. 103, IX), “distinguem-se claramente das **centrais sindicais**, pois aquelas associações de grau superior, posicionadas no ápice da pirâmide sindical, representam, enquanto uniões compostas que são, **uma só** categoria econômica ou profissional, enquanto que estas — as centrais sindicais — apresentam-se **superpostas** às próprias categorias” (**ADI 271-MC**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24.09.1992, Plenário, *DJ* de 06.09.2001, fls. 145).

173 Muito embora a “letra da lei” determine a apresentação em “duas vias”, entendemos que com o **processo eletrônico** essa regra perde o seu sentido. Como se sabe, dentre outras ações, desde o advento da **Res. n. 417/2009-STF**, a ADI passou a ser processada, **exclusivamente**, no sistema eletrônico do STF (**e-STF**, atualmente em sua segunda versão — *Pet V2*, tendo sido lançada ao público em 15.08.2011).

174 Sobre o tema, cf. a ideia da **sociedade aberta dos intérpretes da Constituição**: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição, desenvolvido no *item 3.9* deste estudo.

175 As audiências públicas podem ser acompanhadas no site do STF <<http://www.stf.jus.br/portal/audienciapublica>>. Nesse estudo, cf. *item 3.9*.

176 Seguindo a orientação firmada no *leading case* citado, qual seja, **ADI 2.130**, cf., entre outros: ADI 1.797/PE-AgR, Tribunal Pleno, AI 726.763/SP, RE 556.331/MG, RE 560.197/RJ, RE 568.354/PR, RE 579.760-ED/RS, RE 594.709/SP, RE 603.293-AgR/SP, ADI 633.998/RS, RE 579.760/RS-ED, AI 788.453/SC, RE 375.525/MG, RE 670.890-AgR/SP etc. Nesse sentido da não aplicação do art. 188 do CPC/73 (e, por coerência lógica, da não aplicação dos arts. 180, 183 e 186 do CPC/2015), ao processo objetivo de

controle de constitucionalidade, também a doutrina. Cf. Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, 9. ed., p. 49-50, item 3.3.6.

177 “Ação direta de inconstitucionalidade e prazo decadencial: o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade não está sujeito à observância de qualquer prazo de natureza prescricional ou de caráter decadencial, eis que atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Súmula 360. Precedentes do STF” (STF, Pleno, ADI-MC 1.247/PA, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 1, de 08.09.1995, p. 28354).

178 De acordo com o § 2.º do referido art. 7.º, como visto acima, o relator, considerando a **relevância da matéria** e a **representatividade dos postulantes**, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.

179 Antes da instituição da Lei n. 9.868/99 (art. 26), vigorava, com o caráter de lei ordinária, o **art. 333, IV, do RISTF**, recepcionado pela CF/88, o qual **admitia** a interposição de **embargos infringentes**, por exemplo, em uma **decisão não unânime** tomada por 6 x 5 em ADI, objetivando fazer valer o entendimento vencido. **Contudo**, a partir do advento da referida lei, o atual entendimento é no sentido do **não cabimento dos embargos infringentes**, tendo a nova regra (art. 26 da Lei n. 9.868/99) revogado o **RISTF**. Assim, pode-se afirmar estarem **revigoradas** as **Súmulas 293** (aprovada em 13.12.1964) e **455/STF** (aprovada em 1.º.10.1964), que **vedam** a interposição dos embargos infringentes. Cabe lembrar, **todavia**, jurisprudência do STF que, **excepcionalmente**, admite os embargos infringentes se a “decisão embargada” não unânime foi proferida **antes** da vigência da nova Lei n. 9.868/99. (Nesse sentido, cf. **ADI 1.591-EI**, Rel. Sepúlveda Pertence, j. 27.11.2002, e **ADI 1.289-EI**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.04.2003.)

180 No mesmo sentido: **ADI 4.246**, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, j. 10.05.2011, *DJE* de 20.05.2011; **ADI 4.067-AgR**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.03.2010, Plenário, *DJE* de 23.04.2010; **RE 586.453**; **ADI 4.214**; **ADI 3.978**; **ADI 2.669** etc.

181 Gustavo Santana Nogueira, *Do amicus curiae*, *Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, n. 63, p. 13-28. abr./jun. 2005.

182 Em interessante decisão, o STF admitiu o *amicus curiae* nessa hipótese dos Juizados, e, inclusive, no próprio âmbito do STF (cf. *Inf. 402/STF*, RE 416.827/SC e 415.454/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 21.09.2005).

183 Cf. a admissão do então Senador da República, Pedro Taques, como *amicus curiae* no julgamento do MS 32.033 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.05.2013), **apesar de haver jurisprudência firme da Corte no sentido da não admissão do referido instituto do “amigo da corte” nas ações de mandado de segurança** (MS 29.192, j. 19.08.2014).

184 Art. 7.º, § 2.º: “O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, **por despacho irrecorrível**, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades” (*vide* correspondência no art. 138, *caput*, do CPC/2015).

185 Cf., ainda, Sepúlveda Pertence, na **ADI 2.591** — fls. 18, que sustenta o cabimento de agravo; ou o Ministro Marco Aurélio, na **ADI 3.346**, que sustenta o cabimento de **embargos de declaração**, mas, mantida a decisão de indeferimento, **não admite a interposição de agravo regimental**.

186 “Coerente com evolução constatada no Direito Constitucional comparado, a presente proposta permite que o próprio Supremo Tribunal Federal, por uma maioria diferenciada, decida sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, fazendo um juízo rigoroso de ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional, de um lado, e os postulados da segurança jurídica e do interesse social, de outro (art. 27). Assim, o princípio da nulidade somente será afastado ‘in concreto’ se, a juízo do próprio Tribunal, se puder afirmar que a declaração de nulidade acabaria por distanciar-se ainda mais da vontade constitucional. Entendeu, portanto, a Comissão que, ao lado da ortodoxa declaração de nulidade, há de se reconhecer a possibilidade de o Supremo Tribunal, em casos excepcionais, mediante decisão da maioria qualificada (dois terços dos votos), estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, proferindo a inconstitucionalidade com eficácia *ex nunc* ou *pro futuro*, especialmente naqueles casos em que a declaração de nulidade se mostre inadequada (v. g.: lesão positiva ao princípio da isonomia) ou nas hipóteses em que a lacuna resultante da declaração de nulidade possa dar ensejo ao surgimento de uma situação ainda mais afastada da vontade constitucional” (Gilmar Ferreira Mendes. *Processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal: uma proposta de projeto de lei*, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_06/processo_julgamento.htm>).

187 “A EC 3/93... ao criar a ação declaratória de constitucionalidade de lei federal, prescreveu que a decisão definitiva de mérito nela proferida — incluída, pois, aquela que,

julgando improcedente a ação, proclamar a inconstitucionalidade da norma questionada —, ‘produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo...’. A partir daí, é mais que razoável sustentar que, **quando cabível em tese a ação declaratória de constitucionalidade, a mesma força vinculante haverá de ser atribuída à decisão definitiva da ação direta de inconstitucionalidade**. E, onde haja eficácia vinculante, caberá reclamação para assegurá-la” (Rcl 621/RS, Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 1.º.09.1996, p. 25367. *Vide* também voto em ADCQO-1). Segundo David Araujo e Serrano Nunes, de maneira mais restritiva, referidos efeitos vinculantes só caberiam à ADC, concluindo nos seguintes termos: “portanto, entendemos que o dispositivo só poderia ser aplicado às ações declaratórias de constitucionalidade, não podendo se estender às ações diretas de inconstitucionalidade, por ausência de efeito vinculante no texto constitucional (o que ocorre com a declaratória)” (*Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 47-48).

188 Cf.: **Rcl (AgR-QO) 1.880-SP**, Rel. Min. Maurício Corrêa, 06.11.2002, e **Inf. 289/STF** de 04 a 08.11.2002.

189 **2/3** de **11** Ministros equivalem a $(2 \times 11) \div 3 = 7,333333333...$ Como o art. 27 da Lei n. 9.868/99 falou em *quorum* de 2/3, deve ser entendido no mínimo 2/3. Arredondando o resultado para baixo, teríamos um número inferior a 2/3. Logo, devemos arredondá-lo para cima, e o *quorum* será de pelo menos **8 Ministros**, lembrando o *quorum* de **instalação da sessão de julgamento**, também de **8 Ministros** (art. 22 da Lei n. 9.868/99).

190 Cf. *RTJ* 151/331. De acordo com as anotações jurisprudenciais de Luís Roberto Barroso, “ainda no regime constitucional anterior, o STF, no julgamento do Processo Administrativo 4.477/72, estabeleceu o entendimento de que a **comunicação ao Senado** (acrescente-se, art. 52, X), **somente é cabível na hipótese de declaração incidental de inconstitucionalidade**, isto é, na apreciação de **caso concreto**. No **controle** por via **principal concentrado**, a **simples decisão da Corte, por maioria absoluta, já importa na perda de eficácia da lei ou ato normativo**” (STF, *DJU* de 16.05.1977, p. 3123 — grifamos).

191 Como nosso leitor atento tem conhecimento, o *Decreto-lei n. 4.657/42* introduziu em nosso ordenamento a então denominada *LICC (Lei de Introdução ao Código Civil)*, que, à época, já extrapolava o direito civil, seja por regular a validade, eficácia, vigência, interpretação, revogação das normas, seja por definir conceitos amplos como o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, seja, de modo geral, por apresentar um

- inegável caráter universal, aplicando-se aos demais “ramos” do direito. Por esse motivo, a **Lei n. 12.376/2010** passou a denominá-la **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)**, mantendo intacto o seu conteúdo.
- 192 Todo o conteúdo desse *item 6.7.1.17.4* foi retirado, com algumas adaptações, de Pedro Lenza, *Coisa julgada erga omnes*: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante (no prelo, originalmente defendido como tese de doutorado — USP).
- 193 Para uma interessante crítica terminológica, cf. J. C. Barbosa Moreira, Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material, *Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro*, 62/43-44.
- 194 “Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V — violar literal disposição de **lei**”. Barbosa Moreira, na linha de interpretação já sustentada por Pontes de Miranda (*Comentários ao CPC — de 1973*, t. VI, p. 233; *Tratado da ação rescisória*, 5. ed., p. 299), defende que “**lei**” deve ser interpretada em **sentido amplo**, compreendendo, portanto, além das espécies normativas do art. 59 da CF/88, a própria **Constituição** (cf. J. C. Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973*, 12. ed., v. V, p. 130-131).
- 195 Em sentido contrário, restringindo o cabimento da ação somente na hipótese de superveniente declaração de **inconstitucionalidade** (procedência da ADI ou improcedência da ADC), cf. A. P. Grinover, Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional, *RePro* 87/45-47.
- 196 S. 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
- 197 I. G. da S. Martins, G. F. Mendes, *Controle concentrado de constitucionalidade*: comentários à Lei n. 9.868, de 10.11.99, p. 405-406 e 526.
- 198 O Novo CPC/2015, para a hipótese dos **embargos rescisórios** (cf. *item 6.7.1.17.4.3*), adotou como marco temporal para o ajuizamento da ação rescisória o **trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF**, o que entendemos flagrantemente inconstitucional, como discutimos no referido item (cf. arts. 525, § 15 e 535, § 8.º, do CPC/2015).
- 199 Esta passagem foi recontada por *James Baldwin* e consiste na história de um rei, chamado Dionísio, que governava Siracusa, a cidade mais rica da Sicília, no século IV a.C.

O monarca tinha um amigo chamado Dâmocles, que sempre invejou a sua riqueza e poder. Depois de tanto atormentá-lo, Dionísio, um dia, resolveu trocar de lugar com Dâmocles. Este, dizendo estar vivendo o dia mais feliz de sua vida, foi levado ao palácio e se deleitou com tanta luxúria. Sentado à mesa, com farta comida, bebida e mordomias, Dâmocles percebeu que sob a sua cabeça pendia uma afiada espada, presa por um único fio de pequeníssima espessura e colocada por Dionísio. Paralisado, Dâmocles não conseguia se mover sob a ameaça de qualquer movimento mais brusco romper o frágil fio. Foi aí que Dionísio lhe mostrou que a riqueza e o poder trazem, insitos a eles, o eterno perigo. Sempre sobre a sua cabeça, anotou o monarca, pende uma espada, com lâminas afiadíssimas, havendo o risco, a qualquer momento, de se romper. Dâmocles, então, assustadíssimo, nunca mais quis trocar de lugar com o rei. Assim, a expressão **“a espada de Dâmocles”** significa **“um eterno, iminente, ameaçador e incerto perigo sobre a vida de alguém”**. No contexto da **coisa julgada**, a possibilidade incerta e permanente de reabertura do processo, gerando a inconveniente angústia de o processo ser reaberto a qualquer momento, causando desconcertante insegurança jurídica, é, sem dúvida, uma combatida **“espada de Dâmocles”**. Interessante a utilização desta expressão por José Afonso da Silva ao comentar o art. 18 da Lei da Ação Popular, que permite a reabertura do processo em caso de julgamento por “deficiência probatória”. Em suas palavras, “... é uma sentença que não atua o direito objetivo. Deixa em suspenso a lide, como uma **espada de Dâmocles** pendente sobre o réu” (SILVA, J. A., *Ação popular constitucional: doutrina e processo*, 1968, n. 235, p. 254).

200 Pedro Lenza, *Coisa julgada erga omnes: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante* (no prelo, originalmente defendido como tese de doutorado — USP).

201 Nesse sentido, consolidando o **novo entendimento**, cf.: **RE 353.657**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.06.2007, Plenário, *DJE* de 07.03.2008 e **RE 370.682**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2007, Plenário, *DJE* de 19.12.2007.

202 Para Streck, a “relativização da coisa julgada” pode ser caracterizada como um exemplo do que denominou **“predadores internos do direito”** (*Verdade e consenso*, 5. ed., p. 219-220).

203 **Art. 926, CPC/2015**: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la **estável, íntegra e coerente**”.

204 “Art. 927, § 3.º: Na hipótese de **alteração de jurisprudência dominante** do Supremo

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, **pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica**. § 4.º A modificação de enunciado de súmula, de **jurisprudência pacificada** ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de **fundamentação adequada e específica**, considerando os **princípios da segurança jurídica**, da **proteção da confiança** e da **isonomia**.”

205 Em **30.05.2006**, o Conselho Federal da OAB, com pedido de liminar, ajuizou a **ADI 3.740**, buscando declarar a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais, tendo por fundamento os princípios da **segurança jurídica** e da **autoridade do Poder Judiciário** (*Notícias STF*, 1.º.06.2006). Referida ADI foi distribuída por prevenção à **ADI 2.418**, também ajuizada pelo Conselho Federal da OAB e que objetivava a declaração de inconstitucionalidade do art. 741, parágrafo único, na redação dada pela MP n. 2.180-35/2001. Pela inconstitucionalidade, bastante convincente o estudo de Flávio Luiz Yarshell, *Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório*, p. 254-258 (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

206 Nesse sentido, cf. AI 723.357/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 593.160/RN, Rel. Min. Eros Grau; RE 486.579-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 592.912/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 504.197-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 443.356-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 473.715-AgR/CE, Rel. Min. Ayres Britto; RE 431.014-AgR/RN, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

207 Isso significa que, no **período do recesso**, o **Presidente do Tribunal** será o competente para apreciar a medida cautelar. Mas, como salientou o Ministro Carlos Velloso, “... o presidente do Tribunal, no **recesso**, competente para despachar o pedido de cautelar, somente deverá fazê-lo em caso de **efetiva necessidade**, vale dizer, na **ocorrência da possibilidade de perecimento de direito**”. E durante as **férias seria também possível despachar e, se for o caso, conceder o pedido de cautelar?** Segundo o ilustre Ministro, “... outra questão se apresenta: o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal distingue **recesso** de **férias**. Estabelece o art. 13, VIII, que são atribuições do Presidente decidir, nos períodos de recesso ou de férias, pedido de medida cautelar. E mais: o art. 78 do mencionado Regimento Interno dispõe que ‘o ano judiciário no Tribunal divide-se em dois períodos, recaindo as férias em janeiro e julho’. O § 1.º do mencionado art. 78 conceitua o recesso: ‘Constituem recesso os feriados forenses compreendidos entre os dias 20 de dezembro e 1.º de janeiro, inclusive’. Acrescenta o § 2.º que, ‘Sem prejuízo do disposto no inciso VIII do art. 13, suspendem-se os trabalhos do

Tribunal durante o recesso e as férias, ...'. E o § 3.º novamente se refere ao recesso e às férias: 'Os Ministros indicarão seu endereço para eventual convocação durante as férias ou recesso'. *Ora, a Lei 9.868, de 10.11.99, somente ressalva o período de recesso, ao prescrever, conforme vimos, que, 'Salvo no período de recesso, ...'. É dizer, a Lei 9.868, de 1999, art. 10, somente permite a concessão da medida cautelar, pelo presidente do Tribunal, no período de recesso do Tribunal.* Admito que, ocorrente, durante as **férias**, em ação direta, a *possibilidade de perecimento do direito, será lícito ao presidente despachar o pedido e concedê-la, se for o caso.* Fora daí, entretanto, não me parece possível, tendo em consideração o art. 10 da Lei 9.868/99 e os dispositivos regimentais indicados, que distinguem período de recesso de período de férias" (ADI-2.380/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 07.02.2001, p. 13).

208 "Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do STF proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. — Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como **sujeito processual**, a própria parte reclamante. — O remédio constitucional da reclamação **não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual** destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. — A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'I', da Carta Política (*RTJ* 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (**Rcl 4.381-AgR**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.06.2011, Plenário, *DJE* de 05.08.2011).

209 Cf. RclQO 518/BA, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 24.10.1997, p. 54149, *Ement.* v. 01888-01, p. 18; Rcl 397-RJ, Celso de Mello, *RTJ* 147/31; Rcl 399/PE, Sepúlveda Pertence, *RTJ* 157/433; Rcl 556/TO, Maurício Corrêa, *DJU* de 03.10.1997; Rcl 1.149/RS, Celso de Mello, *DJU* de 29.10.1999, p. 37; Rcl 1.280/SP, Maurício Corrêa, *DJU* de 03.03.2000; Rcl 1.688/BA, Rel. Min. Maurício Corrêa; *DJ* de 22.09.2000, p. 99.

210 Cf.: **Rcl (AgR-QO) 1.880-SP**, Rel. Min. Maurício Corrêa, 06.11.2002 (*Inf.* 289/STF, de 04 a 08.11.2002, *DJ* de 19.03.2004).

211 “O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação — no ‘balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação — que surgirá com maior nitidez a oportunidade para **evolução interpretativa** no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição” (**Rcl 4.374**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013, Plenário, *DJE* de 04.09.2013).

212 Cf. **Rcl 336/DF**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.1990, Pleno, *DJ* de 15.03.1991, p. 2644, *RTJ* 134-03/1033.

213 A. P. Grinover, Da reclamação, *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 38/80.

214 Pedro Lenza, *Coisa julgada* erga omnes: processo coletivo, controle de constitucionalidade e súmula vinculante (originalmente defendido como tese de doutorado — USP).

215 A. P. Grinover, Da reclamação, p. 79-81. Enfocando a **constitucionalidade** da previsão do instituto da reclamação no Regimento Interno do TJSP, cf. A. P. Grinover, A reclamação para garantia da autoridade das decisões dos tribunais, *Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro*, 10/1-9. Sobre o assunto, cf., ainda, C. R. Dinamarco, A reclamação no processo civil brasileiro, *Revista do Advogado*, 61/104-110, e G. S. F. Góes, A reclamação constitucional, in Nelson Nery Junior e Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.), *Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais*, p. 123-145. Sobre a previsão da reclamação no âmbito do Regimento Interno do TJ Estadual, “... o Tribunal, por maioria, acompanhou o voto proferido pela Ministra Ellen Gracie, relatora, no sentido de julgar improcedente o pedido, afastando a alegada ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I), por entender que,

de acordo com o **princípio da simetria**, a Constituição estadual pode autorizar a utilização do instituto da reclamação pelo tribunal de justiça, a teor do disposto no art. 125 da CF. O Min. Sepúlveda Pertence, em seu voto, salientou que a utilização da reclamação no âmbito da justiça estadual insere-se no **poder implícito a ela conferido para assegurar efetividade às próprias decisões**. Vencidos os Ministros Maurício Corrêa, Moreira Alves e Sydney Sanches, que julgavam procedente o pedido. ADI n. 2.212-CE, Rel. Ministra Ellen Gracie, 02.10.2003 (ADI-2212)” (original sem grifos — cf. *Inf. 323/STF*).

216 “ADI: dispositivo do RI do TJ/PB (art. 357), que admite e disciplina o processo e julgamento de reclamação para preservação da sua competência ou da autoridade de seus julgados: ausência de violação dos artigos 125, *caput*, e § 1.º, e 22, I, da Constituição Federal. O STF, ao julgar a ADI 2.212 (Pl. 2-10-03, Ellen, *DJ* 14-11-2003), alterou o entendimento — firmado em período anterior à ordem constitucional vigente (v. g., Rp 1.092, Pleno, Djaci Falcão, *RTJ* 112/504) — do monopólio da reclamação pelo STF e assentou a adequação do instituto com os preceitos da Constituição de 1988: de acordo com a sua natureza jurídica (**situada no âmbito do direito de petição previsto no art. 5.º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal**) e com os princípios da simetria (art. 125, *caput*, e § 1.º) e da efetividade das decisões judiciais, é **permitida a previsão da reclamação na Constituição Estadual** (...)” (ADI 2.480, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Cf., ainda, *Inf. 462/STF*.

217 ADC 1-1/DF, voto do Ministro relator Moreira Alves.

218 *Vide*, por exemplo, o posicionamento do Ministro Marco Aurélio na Reclamação n. 1.197-6/PB, *DJ* de 22.11.1999, p. 2, que entende o efeito vinculante apenas para as **decisões definitivas de mérito**.

219 “Retomando o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (v. *Informativo* 98), proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, que tem por objeto o artigo 1.º da Lei 9.494/97 (‘Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5.º e seu parágrafo único e 7.º da Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1.º e seu § 4.º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1.º, 3.º e 4.º da Lei 8.347, de 30 de junho de 1992.’), o Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia *ex nunc* e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada,

contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n. 9.494, de 10.9.97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam. Precedente citado: ADI-MC 1.576-DF (v. *Informativo* 67). ADC (MC) 4-DF, Rel. Min. Sydney Sanches, 11.2.98” (*Inf.* 99/STF). Cf., ainda, *Inf.* 166/STF: “É cabível a concessão de efeito vinculante a medidas liminares proferidas em sede de ação declaratória de constitucionalidade (CF, art. 102, § 2.º) porquanto o poder geral de cautela é inerente ao poder jurisdicional. Com esse fundamento, o Tribunal, por maioria, conheceu do pedido de medida liminar na ação declaratória de constitucionalidade acima mencionada com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante. Vencido o Min. Marco Aurélio, que não conhecia do pedido, por entender incabível a medida cautelar em se tratando de ação declaratória de constitucionalidade em face de seu efeito vinculante. Precedente citado: ADCMC 4-DF (*DJU* de 21.5.99). ADC 8-DF, Rel. Min. Celso de Mello, 13.10.99”.

220 Conforme salientou o Ministro Sydney Sanches: “Ementa: 1 (...) trata-se de **competência** cujo exercício ainda **depende de Lei**. 4. Também não compete ao STF elaborar Lei a respeito, pois essa é missão do Poder Legislativo (arts. 48 e seguintes da CF). 5. E nem se trata aqui de Mandado de Injunção, mediante o qual se pretenda compelir o Congresso Nacional a elaborar a Lei de que trata o § 1.º do art. 102, se é que se pode sustentar o cabimento dessa espécie de ação, com base no art. 5.º, inciso LXXI, visando a tal resultado, não estando, porém, ‘*sub judice*’, no feito, essa questão. 6. Não incide, no caso, o disposto no art. 4.º da Lei de Introdução ao Código Civil (atualmente, acrescente-se, nos termos da Lei n. 12.376/2010, *Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro*), segundo o qual ‘quando a lei for omissa, o Juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito’. É que não se trata de lei existente e omissa, mas, sim, de lei inexistente. 7. Igualmente não se aplica à hipótese a 2.ª parte do art. 126 do Código de Processo Civil, ao determinar ao Juiz que, não havendo normas legais, recorra à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, para resolver lide ‘*inter partes*’. Tal norma não se sobrepõe à constitucional, que, para a arguição de descumprimento de preceito fundamental dela decorrente, perante o STF, **exige Lei formal, não autorizando, à sua falta, a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito**” (AGRPET 1140/TO, Rel. Min. Sydney Sanches, *DJ* de 31.05.1996, p. 18803, *Ement.* v. 01830-01, p. 1, Pleno).

- 221 Gilmar Ferreira Mendes, *Curso de direito constitucional*, 6. ed., p. 1235.
- 222 Inédito, especial aos alunos do Curso do Professor Damásio.
- 223 *Constituição Federal anotada*, p. 901.
- 224 “... A arguição de descumprimento de preceito fundamental poderá ser proposta pelos **legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade** (Lei n. 9.882/99, art. 2.º, I), mas qualquer interessado poderá solicitar ao Procurador-Geral da República a propositura da arguição (art. 2.º, § 1.º). Assim posta a questão, porque o autor não é titular da *legitimatio ad causam* ativa, nego seguimento ao pedido e determino o seu arquivamento...” (Min. Carlos Velloso, ADPF-11/SP, DJ de 06.02.2001, p. 294).
- 225 Como destacou o Min. Marco Aurélio, os **embargos declaratórios** são **ínsitos** à **jurisdição** e cabíveis **independentemente de previsão legal** (AP 470 AgR, 26.º, *Inf. 719/STF*, item 8). Em suas palavras, os embargos de declaração devem ser vistos com espírito maior de compreensão. “Não como uma crítica ao ofício de julgar, mas como **colaboração** das partes ao **aperfeiçoamento** da prestação jurisdicional. Os embargos visam à **integração** ou **esclarecimento** da decisão proferida. Os vícios que os respaldam dizem respeito ao mérito, não a pressupostos de recorribilidade. Refiro-me à omissão, à contradição e à obscuridade. Admito, até mesmo, a possibilidade de ter-se os segundos declaratórios, quando o vício haja surgido, pela vez primeira, no julgamento dos anteriores” (fls. 37).
- 226 Cf. *Notícias STF*, 22.08.2006 — 19h00.
- 227 *Vide capítulo 5*, sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.
- 228 Sobre o assunto, cf. nova posição do STF dada no **MI 712** e discutida nesta obra no *item 14.11.5.4*. Nessa parte do estudo apresentamos outros temas, destacando-se, por exemplo, o julgamento de vários MIs sobre o direito fundamental dos trabalhadores ao **aviso prévio proporcional ao tempo de serviço**, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei (art. 7.º, XXI), no caso, da Lei n. 12.506/2011, que regulamentou o assunto. A esse respeito, interessante a discussão em vários mandados de injunção ajuizados antes do advento da regulamentação, quando a **omissão** era **total** (cf. MIs 943, 1.010, 1.074 e 1.090, j. 22.06.2011).
- 229 Luís Roberto Barroso, *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*, 2. ed., p. 229-230.
- 230 “A ação direta de inconstitucionalidade por omissão fica prejudicada, por perda de

objeto, quando **revogada a norma que necessite de regulamentação para sua efetividade**. Com base nesse entendimento, o Tribunal, resolvendo questão de ordem, julgou **prejudicada** ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República em que se pretendia declarar a inconstitucionalidade por omissão do Governador do Estado de São Paulo na adoção de medida necessária para dar efetividade ao art. 241 da CF, no seu texto originário (‘Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do art. 39, § 1.º, correspondente às carreiras disciplinadas no art. 135 da Constituição’), uma vez que a EC 19/98 deu nova redação ao referido art. 241 da CF, dispondo sobre matéria diversa (‘A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços prestados’))” (ADI 1.836-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 18.06.1998).

231 Esse entendimento **superado** da jurisprudência do STF pode ser verificado, por exemplo, no julgamento da *ADI 1.439-MC*, voto do Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.05.1996, Plenário, *DJ* de 30.05.2003.

232 *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 230.

233 Dentro de uma ideia de poder geral de cautela, destacamos interessante decisão do Min. Dias Toffoli, concedendo medida cautelar **monocraticamente**, *ad referendum* do Plenário, de modo excepcional, diante da relevância da matéria e da gravidade do quadro narrado, bem como da proximidade do recesso da Corte (cf. **ADO 24-MC**, j. 1.º.07.2013), fixando prazo de 120 dias para que o Congresso Nacional edite a lei prevista no art. 27 da EC n. 19/98 — **lei de defesa do usuário de serviços públicos**). Em igual sentido, também concedendo medida cautelar monocraticamente, cf. **ADO 23-MC**, j. 24.01.2013, Min. Ricardo Lewandowski.

234 O acórdão pode ser encontrado no site do STF (<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp>), digitando o número 3682; aguardamos as observações e comentários de nossos ilustres leitores para saber qual a melhor interpretação a que chegaram (pedrolenza@terra.com.br), apesar do esclarecimento, em 12.09.2008, pelo Ministro Gilmar Mendes, por meio de Ofício ao Presidente da CD, no sentido de se tratar de apelo, fixando-se um parâmetro temporal razoável.

235 Adiantamos observação a ser feita no capítulo sobre *Federação*, de que a CF/88

extinguiu os Territórios que existiam, permitindo, contudo, a criação de novos Territórios Federais, na hipótese do art. 18, § 3.º (cf. *item 7.8.5*).

236 Explicita-se que apenas em determinadas hipóteses será necessário o prévio ajuizamento e procedência da ADI interventiva para se decretar a intervenção federal ou estadual. Os arts. 34 e 35 estabelecem situações nas quais se decreta a intervenção sem a aludida representação de inconstitucionalidade.

237 Clèmerson Merlin Clève, *Fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 125.

238 L. R. Barroso, *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*, 3. ed., p. 306.

239 Conforme anota Buzaid, ao comentar a regra contida no texto de 1946, o constituinte “... empregou a palavra *ato* com significação mais ampla do que a *lei*. Lei é ato oriundo do legislativo. Se toda lei é ato, nem todo ato é lei. O ato, a que alude a regra constitucional, é qualquer ato, oriundo de qualquer dos poderes do Estado, conquanto que ofenda os princípios assegurados no art. 7.º, VII, da Constituição. O intérprete não pode, portanto, limitar onde o legislador manifestamente ampliou, incluindo apenas a *lei* como objeto de apreciação, quando atos dos demais poderes também podem ofender os referidos princípios constitucionais” (*Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro*, p. 120).

240 Querido leitor, vale a leitura do pedido de intervenção no DF formulado pelo Dr. Roberto Gurgel, PGR, que relata fatos *chocantes* e *estranhadores*. A sua íntegra poderá ser encontrada em *Notícias STF*, 11.02.2010 — 21h08.

241 L. R. Barroso, *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*, 3. ed., p. 313-314. No mesmo sentido, C. M. Clève, *A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro*, p. 105-106.

242 Gilmar Mendes, *Curso de direito constitucional*, 6. ed., p. 1345.

243 Nesse sentido, cf. Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, *Controle de constitucionalidade*, 5. ed., p. 157. Manoel Carlos de Almeida Neto, localizando, inclusive, expressa previsão de ADC Municipal positivada, como no art. 101, VII, “f”, da Constituição do Paraná e art. 133, II, “m”, da Constituição do Amapá, conclui: “a partir de uma interpretação sistemática do art. 102, I, ‘a’, c/c o art. 125, § 2.º, ambos da Constituição Federal, e tendo em vista o caráter dúplice ou ambivalente da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, concluo ser

absolutamente cabível a ADC no âmbito municipal com o objetivo de preservar a presunção de constitucionalidade da lei ou do ato normativo municipal” (*O novo controle de constitucionalidade municipal*, p. 157).

244 “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 1988, no sentido de que **não** cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal” (**ADI 347**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 20.09.2006, *DJ* de 20.10.2006. No mesmo sentido: **RE 421.256**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.09.2006, *DJ* de 24.11.2006).

245 Em sede doutrinária, sustentando a parametricidade das cláusulas constitucionais estaduais de caráter remissivo, cf. Manoel Carlos de Almeida Neto, *O novo controle de constitucionalidade municipal*, p. 141.

246 “Coexistência de jurisdições constitucionais estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. **Suspensão do processo** no âmbito da justiça **estadual**, até a deliberação definitiva desta Corte. Precedentes. Declaração de inconstitucionalidade, por esta Corte, de artigos da lei estadual. Arguição pertinente à mesma norma requerida perante a Corte estadual. **Perda de objeto**” (**Pet 2.701-AgR**, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 08.10.2003, *DJ* de 19.03.2004).

- 1 *Elementos de teoria geral do Estado*, 23. ed., p. 118.
- 2 Características essas mantidas pelo povo através do plebiscito convocado conforme o art. 2.º do ADCT: “No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de **plebiscito**, a **forma** (**república** ou **monarquia constitucional**) e o **sistema de governo** (**parlamentarismo** ou **presidencialismo**) que devem vigorar no País”. A EC n. 2/92 estabeleceu novas diretrizes para o aludido artigo do ADCT.
- 3 O art. 1.º, *caput*, fala em “**República Federativa do Brasil**”, sendo repetida tal expressão no art. 18, *caput*.
- 4 Como observam Luiz A. D. Araujo e Vidal S. Nunes Jr., “as **formas de Estado** referem-se à projeção do poder dentro da esfera territorial, tomando como critério a existência, a intensidade e o conteúdo de descentralização político-administrativa de cada um” (*Curso de direito constitucional*, p. 170).
- 5 *Curso de direito constitucional*, p. 72.
- 6 Sobre o assunto, consultar o clássico *O federalista*, de Alexandre Hamilton, John Jay e James Madison, coletânea de artigos refletindo, densamente, as ideologias que inspiraram a Constituição norte-americana.
- 7 Raul Machado Horta, *Direito constitucional*, 4. ed., p. 306-307.
- 8 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, 34. ed., p. 56.
- 9 Augusto Zimmermann, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 392.
- 10 Augusto Zimmermann, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 389, nota 7.
- 11 André Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 7. ed., p. 1049.
- 12 André Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 7. ed., p. 1049.
- 13 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 32. ed., p. 649.
- 14 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, 34. ed., p. 60.
- 15 Redação de acordo com o texto original (A. Campanhole e H. L. Campanhole, *Constituições do Brasil*, p. 751).
- 16 L. P. Mota e C. Spitzcovsky, *Curso de direito constitucional*, p. 74.
- 17 Aprofundamos o tema dos **princípios fundamentais** (arts. 1.º a 4.º da CF/88) no *capítulo 21* do presente estudo.

- 18 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 471-472.
- 19 Celso Bastos, *Curso de direito constitucional*, p. 159-160.
- 20 Como exemplo de instrumento objetivando evitar a concentração de recursos exclusivamente nas unidades de origem, nas hipóteses do art. 155, § 2.º, VII (**antes da EC n. 87/2015**), quando se tratasse de operação interestadual cuja mercadoria era destinada a consumidor final **não contribuinte do imposto**, foi estabelecido o **Protocolo ICMS 21/2011**, Conselho Nacional de Política Fazendária (**Confaz**), que exigia, nas **operações interestaduais por meios eletrônicos ou telemáticos**, o recolhimento de parte do ICMS em favor dos Estados onde se encontravam **consumidores finais dos produtos comprados**. O tema foi analisado pelo **STF** que reconheceu a **inconstitucionalidade** do referido protocolo, com a modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas. Nos *itens* 5 e 10 da ementa, a Corte deixou claro esse entendimento: “O ICMS incidente na aquisição decorrente de **operação interestadual** e por meio **não presencial** (*internet, telemarketing, showroom*) por **consumidor final não contribuinte do tributo** não pode ter regime jurídico fixado por Estados-Membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2.º, VII, “b”, e 150, IV e V, da CRFB/88. (...). Os Estados-Membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detêm competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida” (**ADIs 4.628 e 4.713 e RE 680.089**, com repercussão geral, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.09.2014, Plenário, *DJE* de 24.11.2014).
- 21 Apenas por curiosidade é interessante lembrar que as constelações que figuram na Bandeira Nacional correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia **15.11.1889** (12 horas siderais), e devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste. Serão suprimidas da Bandeira Nacional as estrelas correspondentes aos Estados extintos, permanecendo a designada para representar o novo Estado, resultante de fusão, observado, em qualquer caso, o dever de manter a disposição estética original constante do desenho proposto pelo Decreto n. 4, de 19 de novembro de 1889 (art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da **Lei n. 5.700/71**, na redação dada pela Lei n. 8.421, de 11.05.1992).
- 22 “O Hino Nacional é composto da música de Francisco Manoel da Silva e do poema de Joaquim Osório Duque Estrada, de acordo com o que dispõem os Decretos n. 171, de 20

de janeiro de 1890, e n. 15.671, de 6 de setembro de 1922, conforme consta dos Anexos números 3, 4, 5, 6 e 7. A marcha batida, de autoria do mestre de música Antão Fernandes, integrará as instrumentações de orquestra e banda, nos casos de execução do Hino Nacional, mencionados no inciso I do art. 25 desta Lei, devendo ser mantida e adotada a adaptação vocal, em fá maior, do maestro Alberto Nepomuceno” (art. 6.º da Lei n. 5.700/71). De maneira interessante, a **Lei n. 12.031, de 21.09.2009**, alterou a referida Lei n. 5.700/71, tornando obrigatória a **execução semanal** do Hino Nacional nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental.

23 As Armas Nacionais são as instituídas pelo Decreto n. 4, de 19 de novembro de 1889, com a alteração feita pela Lei n. 5.443, de 28 de maio de 1968 (Anexo n. 8), devendo obedecer à proporção de 15 (quinze) de altura por 14 (quatorze) de largura e atender às diversas disposições do art. 8.º (arts. 7.º e 8.º da Lei n. 5.700/71). De acordo com o art. 26 da referida Lei n. 5.700/71, é **obrigatório o uso das Armas Nacionais**: a) no Palácio da Presidência da República e na residência do Presidente da República; b) nos edifícios-sede dos Ministérios; c) nas Casas do Congresso Nacional; d) no STF, nos Tribunais Superiores e nos “Tribunais Federais de Recursos” (lembrando que referidos Tribunais não estão mais presentes na CF/88, em razão da existência de TRFs e do STJ); e) nos edifícios-sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados, Territórios e Distrito Federal; f) nas Prefeituras e Câmaras Municipais; g) na frontaria dos edifícios das repartições públicas federais; h) nos quartéis das forças federais de terra, mar e ar (entendam-se *Forças Armadas*, quais sejam, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica) e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, nos seus armamentos, bem como nas fortalezas e nos navios de guerra; i) na frontaria ou no salão principal das escolas públicas; j) nos papéis de expediente, nos convites e nas publicações oficiais de nível federal.

24 O art. 27 da Lei n. 5.700/71 estabelece que o Selo Nacional será usado para **autenticar** os atos de governo e bem assim os **diplomas** e certificados **expedidos** pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos.

25 Todas as imagens foram retiradas do site <<http://www2.planalto.gov.br/presidencia/simbolos-nacionais>>.

26 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 430-431.

27 *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 211.

28 O art. 32, *caput*, da CF/88 **veda** a divisão do Distrito Federal em Municípios. Não

existem, portanto, “cidades” no sentido de sede de Município. A expressão “cidade-satélite” mostra-se inadequada. Prefere-se a denominação **Regiões Administrativas** (RAs), modo pelo qual o Distrito Federal se organiza com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida (art. 10 da Lei Orgânica do DF).

29 Constituição de 1891: “Art. 3.º Fica pertencendo à União, no **planalto central da República**, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital federal”.

30 Constituição de 1934: “Art. 4.º, *caput*, das Disposições Transitórias: Será **transferida** a Capital da União para um **ponto central do Brasil**. O Presidente da República, logo que esta Constituição entrar em vigor, nomeará uma Comissão, que, sob instruções do Governo, procederá a estudos de várias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos tais estudos, serão presentes à Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará sem perda de tempo as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado”.

31 Constituição de 1946: “Art. 4.º, ADCT: A Capital da União será **transferida** para o **planalto central do País**. § 1.º Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em sessenta dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital. § 2.º O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União. § 3.º Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança da Capital. § 4.º Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado da Guanabara”.

32 A Lei n. 2.874/1956 dispôs sobre a mudança da Capital Federal, autorizando o Executivo a constituir a *Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP)*. Com projeto urbanístico de **Lúcio Costa** e arquitetônico de **Oscar Niemeyer**, Brasília foi declarada **Patrimônio Mundial** pela **UNESCO**, tendo sido inscrita na listagem oficial em 11.12.1987, confirmando, assim, o seu valor excepcional e universal, devendo o seu sítio cultural ou natural ser protegido para o benefício da humanidade.

33 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 8. ed., p. 252.

34 “Art. 20. São bens da União: I — os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a

ser atribuídos; II — as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; III — os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; IV — as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II (EC n. 46/2005); V — os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VI — o mar territorial; VII — os terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII — os potenciais de energia hidráulica; IX — os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X — as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; XI — as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.”

35 De acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, “**terras devolutas** são as **terras públicas não aplicadas ao uso comum nem ao uso especial**. Sua origem é a seguinte. Com a descoberta do País, todo o território passou a integrar o domínio da Coroa Portuguesa. Destas terras, largos tratos foram trespassados aos colonizadores, mediante as chamadas concessões de sesmarias e cartas de data, com a obrigação de medi-las, demarcá-las e cultivá-las (quando então lhes adviria a confirmação, o que, aliás, raras vezes sucedeu), sob pena de ‘comisso’, isto é, de reversão delas à Coroa, caso fossem descumpridas as sobreditas obrigações. Tanto as terras que jamais foram trespassadas, como as que caíram em comisso, *se não ingressaram no domínio privado por algum título legítimo e não receberam destinação pública, constituem as terras devolutas*. Com a independência do País passaram a integrar o domínio imobiliário do Estado Brasileiro. Pode-se **definir as terras devolutas** como sendo as que, *dada a origem pública da propriedade fundiária no Brasil, pertencem ao Estado — sem estarem aplicadas a qualquer uso público — porque nem foram trespassadas do Poder Público aos particulares, ou, se o foram, caíram em comisso, nem se integraram no domínio privado por algum título reconhecido como legítimo*” (*Curso de direito administrativo*, 12. ed., p. 733).

36 A **EC n. 49/2006** acabou com o monopólio da União sobre a produção, comercialização e utilização de **radioisótopos**, que poderão ser autorizadas sob o **regime de permissão**, conforme as alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do **caput** do art. 21 da CF, nas áreas da

- medicina, agricultura e indústria (cf. *item 20.3*). Em relação à **manutenção do monopólio dos Correios** (art. 21, X), cf. *item 20.2*, **ADPF 46**, j. 05.08.2009.
- 37 *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 820 (grifamos). Amigo professor, interessante, inclusive para ser trabalhada em aula com os alunos, a decisão monocrática do Min. Celso de Mello na **AC-MC/RR 1.255**, DJ de 22.06.2006.
- 38 “Ao Distrito Federal são atribuídas as **competências legislativas reservadas aos Estados** e Municípios.”
- 39 Ver no *item 7.6.2.2* comentários à **competência legislativa suplementar municipal**, onde entendemos também caber a participação municipal suplementando a legislação geral e específica, dentro do interesse local municipal.
- 40 *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 644.
- 41 De acordo com a divulgação do TSE, **66,60%** dos votos válidos refletiram a vontade da maioria contra a criação de Carajás.
- 42 Por sua vez, conforme divulgação do TSE, **66,08%** dos votos válidos também refletiram a vontade popular contra a criação de Tapajós.
- 43 **ADI 2.650**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.08.2011, Plenário, DJE de 16.11.2011.
- 44 *Comentário contextual à Constituição*, 2. ed., p. 249.
- 45 Nesse sentido, destacamos a **LC n. 103/2000**, que, em razão da regra contida no art. 22, parágrafo único, da CF/88, **autorizou** os **Estados** e o **DF** a instituírem, **mediante lei de iniciativa do Poder Executivo**, o **piso salarial** de que trata o art. 7.º, V, da Constituição Federal, para os **empregados** que **não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho** (cf. *item 15.4.1*).
- 46 Ver no *item 7.6.2.2* comentários à **competência legislativa suplementar municipal**, onde entendemos também caber a participação municipal suplementando a legislação geral e específica, dentro do interesse local municipal.
- 47 Porém, lembrar o conteúdo do art. 177, que diz: “Constituem monopólio da União: I — a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II — a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III — a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV — o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo

bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; V — a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, **com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal** (cf. **EC n. 49/2006**). § 1.º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei”.

48 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 36. ed., p. 669.

49 José Afonso da Silva, *Direito urbanístico brasileiro*, 5. ed., p. 159-161. Conforme anotou, “essa *realidade urbanística especial*, que constitui o substrato e fundamento das regiões metropolitanas, foi muito bem captada pela justificativa que acompanhou a proposta de emenda constitucional de autoria do então senador Eurico Rezende, de que se originou o § 10 do art. 157 da Constituição do Brasil de 1967, traduzido no art. 164 da EC 1/1969. *In verbis*: ‘as Regiões Metropolitanas constituem hoje em dia uma *realidade urbanística* que não pode ser desconhecida das Administrações modernas, nem omitida no planejamento regional. Por regiões metropolitanas entendem-se aqueles Municípios que gravitam em torno da grande cidade, formando com esta uma unidade socioeconômica, com recíprocas implicações nos seus serviços *urbanos e interurbanos*. Assim sendo, tais serviços deixam de ser de exclusivo interesse local, por vinculados estarem a toda comunidade metropolitana. Passam a constituir a *tessitura intermunicipal daquelas localidades*, e, por isso mesmo, devem ser *planejados e executados em conjunto, por uma Administração unificada e autônoma, mantida por todos os Municípios da região (...)*’” (*op. cit.*, p. 161).

50 *Elementos de direito constitucional*, p. 112.

51 Alaôr Caffê Alves, Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas dimensões constitucionais da organização do Estado brasileiro, *RPGESP*, p. 40.

52 Nesse sentido, “Emenda Constitucional 15/96. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, nos termos da lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar e após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal. Inexistência da lei complementar exigida pela Constituição Federal. Desmembramento de município com base somente em lei estadual. Impossibilidade” (ADI 2.702, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 05.11.2003, *DJ* de 06.02.2004).

53 Nesse sentido, cf. ADI 2.381-MC/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 14.12.2001; ADI 3.149/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJ* de 1.º.04.2005; ADI 2.702/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 06.02.2004; ADI 2.967/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 19.03.2004; ADI 2.632/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 12.03.2004.

54 ADIs **2.240** (*Lei n. 7.619/2000*, do Estado da Bahia — que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães), **3.316** (*Lei n. 6.983/98*, do Estado do Mato Grosso — que criou o Município de Santo Antônio do Leste, a partir de área desmembrada do Município de Novo São Joaquim), **3.489** (*Lei n. 12.294/2002*, do Estado de Santa Catarina — que anexa ao Município de Monte Carlo a localidade de Vila Arlete, desmembrada do Município de Campos Novos) e **3.689** (*Lei n. 6.066/97*, do Estado do Pará — que, alterando divisas, desmembrou faixa de terra do Município de Água Azul do Norte e integrou-o ao de Ourilândia do Norte).

55 *Elementos de direito constitucional*, p. 106.

56 Sobre o assunto, consultar a **Lei n. 10.257, de 10.07.2001**, denominada **Estatuto da Cidade**, com *vacatio legis* de **90 dias**, que, regulamentando os arts. 182 e 183 da CF/88, trouxe importantes inovações. No tocante ao **plano diretor**, o art. 41 da referida lei diz ser obrigatório para cidades: **a)** com mais de 20.000 habitantes; **b)** integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; **c)** onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4.º do art. 182 da Constituição Federal; **d)** integrantes de áreas de especial interesse turístico; **e)** inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Estabelece, ainda, o art. 41, § 2.º, da referida lei que, no caso de cidades com mais de **500.000 habitantes**, deverá ser elaborado um **plano de transporte urbano integrado**, compatível com o **plano diretor** ou nele **inserido**.

57 Terminologia utilizada por José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 553.

58 Ver comentários à **competência legislativa suplementar municipal**, nos quais entendemos também caber a participação municipal suplementando a legislação geral e específica, dentro do interesse local municipal.

59 “O **nome Acre** surgiu de ‘Aquiri’, que significa ‘rio dos jacarés’ na língua nativa dos índios Apurinãs, os habitantes originais da região banhada pelo rio que empresta o nome ao estado. Os exploradores da região transcreveram o nome do dialeto indígena, dando

origem ao nome Acre. Os primeiros habitantes da região eram os índios, até 1877, quando imigrantes nordestinos arregimentados por seringalistas para trabalhar na extração do látex, devido aos altos preços da borracha no mercado internacional, iniciaram a abertura de seringais. Este território, antes pertencente à Bolívia e ao Peru, foi aos poucos sendo ocupado por brasileiros. Os imigrantes avançaram pelas vias hidrográficas do rio Acre, Alto-Purus e Alto-Juruá, o que aumentou a população de local de brancos em cerca de quatro vezes em um ano” (site <www.ac.gov.br>, “sobre o Acre”, acesso em 1.º.01.2014).

60 Gilmar Mendes, Inocência Coelho e Paulo Branco, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 850.

61 Raul Machado Horta, *Direito constitucional*, 4. ed., p. 309.

62 Gilmar Mendes, Inocência Coelho e Paulo Branco, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 850.

63 Gilmar Mendes, Inocência Coelho e Paulo Branco, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 850.

64 Gilmar Mendes, Inocência Coelho e Paulo Branco, *Curso de direito constitucional*, 4. ed., p. 850.

65 Conforme estabelecido, “os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os **planos de saúde**, tendo em vista a sua **íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro**, notadamente por conta do **componente atuarial**. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de **relações contratuais**, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I)”.

66 Amigo concurseiro, é por isso que dizemos... **não desista dos sonhos**. O momento é passageiro e vai dar certo! Tanta força de vontade vai valer a pena.

67 Humberto Peña de Moraes, Do processo interventivo, no contorno do Estado federal..., in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário: Emenda Constitucional n. 45/2004*, p. 229.

68 Interessante a observação de Michel Temer, que diz: “na verdade, quando a União

intervém em dado Estado, todos os Estados estão intervindo conjuntamente; a União age, no caso, em nome da Federação” (*Elementos de direito constitucional*, p. 79).

69 Nos termos do art. 98 da Lei n. 4.320/64, “a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos”. Trata-se, assim, de **passivo financeiro**.

70 Conforme já alertamos, a alínea “e” do inciso VII do art. 34 da CF/88 tinha sido acrescentada pela EC n. 14/96. Sua redação, contudo, foi alterada pela **EC n. 29, de 13.09.2000**, fazendo constar que a aplicação do mínimo exigido não se restringirá à manutenção e desenvolvimento do **ensino**, mas abrangerá também as **ações e serviços públicos de saúde**, sendo os recursos mínimos para esta última, até o **exercício de 2004**, fixados de acordo com o art. 77 do ADCT (acrescentado pela referida emenda). A partir do **exercício financeiro de 2005**, os recursos mínimos deveriam ser fixados por **lei complementar**, nos termos do art. 198, § 3.º (acrescentado pela EC n. 29/2000). De acordo com o art. 77, § 4.º, do ADCT, na ausência da referida lei complementar, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-iam à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios as regras fixadas no citado art. 77 do ADCT. Essa situação perdurou até o advento da **LC n. 141/2012**, que, além de outras providências, regulamentou o § 3.º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em **ações e serviços públicos de saúde** e estabeleceu os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo.

71 Humberto Peña de Moraes, *Do processo interventivo, no contorno do Estado federal...*, p. 229.

72 Redação dada pela **EC n. 29, de 13.09.2000**.

- 1 Anotou Comparato que a *Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789* “... representa, por assim dizer, o atestado de óbito do *Ancien Régime*, constituído pela monarquia absoluta e pelos privilégios feudais, e, neste sentido, volta-se claramente para o passado. Mas o seu carácter abstrato e geral das fórmulas empregadas, algumas delas lapidares, tornou a Declaração de 1789, daí em diante, uma espécie de **carta geográfica fundamental** para a navegação política nos mares do futuro, uma referência indispensável a todo projeto de constitucionalização dos povos” (Fábio Konder Comparato, *A afirmação histórica dos direitos humanos*, 7. ed., p. 163 — original sem grifos).
- 2 Art. 16. “Toda sociedade, na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a **separação dos poderes** determinada, não tem Constituição” (tradução livre do autor: “*Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution*”).
- 3 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, 34. ed., p. 135.
- 4 Dimitri Dimoulis, *Significado e atualidade da separação de poderes*, p. 145-146. Nesse sentido, para aprofundamento, cf. Nuno Piçarra, *A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional*, passim. Ainda, conforme estabeleceu Dallari, “o sistema de separação de poderes, consagrado nas Constituições de quase todo o mundo, foi associado à ideia de **Estado Democrático** e deu origem a uma engenhosa construção doutrinária, conhecida como **sistema de freios e contrapesos**. Segundo essa teoria os atos que o Estado pratica podem ser de duas espécies: ou são **atos gerais** ou são **especiais**. Os **atos gerais**, que só podem ser praticados pelo **poder legislativo**, constituem-se na emissão de regras gerais e abstratas, não se sabendo, no momento de serem emitidas, a quem elas irão atingir. Dessa forma, **o poder legislativo**, que só pratica atos gerais, **não atua concretamente na vida social**, não tendo meios para cometer abusos de poder nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a um grupo em particular. Só depois de emitida a norma geral é que se abre a possibilidade de atuação do **poder executivo**, por meio de **atos especiais**. O executivo dispõe de **meios concretos para agir**, mas está igualmente impossibilitado de atuar discricionariamente, porque todos os seus atos estão **limitados pelos atos gerais praticados pelo legislativo**. E se houver exorbitância de qualquer dos poderes surge a **ação fiscalizadora do poder judiciário**, obrigando cada um a permanecer nos limites de sua respectiva esfera de competência” (Dalmo de Abreu Dallari, *Elementos de teoria geral do Estado*, p. 184-185) (o original não está “negrito”).

- 5 Como se sabe, no constitucionalismo brasileiro e de modo geral, a regra adotada é a da **tripartição**. Lembramos, contudo, o art. 10 da Constituição do Império de 1824, que adotou a separação **quadripartita**: “Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são **quatro**: o **Poder Legislativo**, o **Poder Moderador**, o **Poder Executivo**, e o **Poder Judicial**”.
- 6 Interessante notar, de modo excepcional, o art. 1.º, I, da **Nova Lei Fundamental da Cidade do Vaticano**, que entrou em vigor em 22.02.2001 e substituiu integralmente a anterior, de 7 de junho de 1929: “O **Sumo Pontífice**, Soberano do Estado da Cidade do Vaticano, **tem a plenitude dos poderes legislativo, executivo e judicial**” (cf. íntegra do texto em <http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/index.htm>).
- 7 Cabe alertar, contudo, como sinalizou Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que “o próprio Montesquieu abria exceção ao princípio da separação ao admitir a intervenção do chefe de Estado, pelo *veto*, no processo legislativo” (*Curso de direito constitucional*, 34. ed., p. 137).
- 8 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 35. ed., p. 108.
- 9 Celso R. Bastos, *Curso de direito constitucional*, p. 340.
- 10 Idem, *ibidem*.
- 11 Devemos lembrar que as Constituições de **1946** e **1967** e a **EC n. 1/69** adotaram uma redação melhor que a do art. 92 da CF/88, seguindo o “padrão” redacional estabelecido para os outros “poderes”, nos seguintes termos: “O ‘Poder’ Judiciário (*função*) é exercido pelos seguintes órgãos” (“*órgão*” — com a indicação, como se observa no texto atual).

- 1 O número mínimo de Deputados Estaduais será 24, já que o número mínimo de Deputados Federais é 8, nos termos do art. 45, § 1.º, da CF/88.
- 2 Essa pergunta, por incrível que pareça, caiu no *X Concurso de Juiz do Trabalho da 14.ª Região — Rondônia e Acre*. No mesmo sentido, podemos destacar questão exigindo esse conhecimento na prova de *Agente Administrativo — PRF — CESPE/UnB/2012* — (vide questões ao final deste capítulo, *item 9.16*). Então, amigos concurseiros, vejam que, muitas vezes, um pequeno detalhe faz a diferença..., apesar de, em nosso entender, esse tipo de questão não medir o verdadeiro conhecimento. A fórmula para o sucesso? Muito estudo! Mas estudo estratégico! Isso significa que fazer questões de provas do concurso almejado e de outros pode orientar e encurtar a caminhada! Muito sucesso e contem comigo!
- 3 O número máximo de Deputados Estaduais será de 94, já que o número máximo de Deputados Federais é de 70, nos termos do art. 45, § 1.º, da CF/88.
- 4 Contra referida EC n. 58/2009, em **29.09.2009**, foi proposta a **ADI 4.307** pelo Procurador-Geral da República e, em 02.10.2009, a Ministra Cármen Lúcia deferiu liminar suspendendo a eficácia do art. 3.º, I, da EC n. 58/2009, **evitando**, desse modo, o *preenchimento imediato de quase 7 mil vagas* então criadas pela denominada “PEC dos Vereadores”. Referida liminar foi referendada pelo Plenário do STF em 11.11.2009, tendo sido concedida liminar também na ADI 4.310 ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. Em 11.04.2013, o Plenário do STF julgou procedente o pedido formulado na referida ADI para **declarar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3.º da EC 58/2009**. Vejamos: “EC 58/2009. Alteração na composição dos limites máximos das câmaras municipais. Inciso IV do art. 29 da CR. (...) Posse de novos vereadores: impossibilidade. **Alteração do resultado de processo eleitoral encerrado**: inconstitucionalidade. Contrariedade ao art. 16 da CR. (...) Norma que determina a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das câmaras municipais em pleito ocorrido e **encerrado**: afronta à garantia do exercício da **cidadania popular** (arts. 1.º, parágrafo único, e 14 da Constituição) e a **segurança jurídica**...” (ADI 4.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.04.2013, Plenário, *DJE* de 1.º.10.2013).
- 5 Assim, por curiosidade, fazendo uma conta rápida, se o subsídio máximo dos Deputados Estaduais corresponde a 75% do subsídio em espécie dos Deputados Federais, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a **56,25%** do subsídio em espécie fixado para os Deputados Federais.
- 6 Para as provas, recomendamos a leitura atenta dos arts. 48 e 49.

- 7 Entendam-se por **povo** os brasileiros natos e naturalizados descritos no art. 12 da CF/88. Confira a importante novidade trazida pela EC n. 54/2007 e apresentada no *item 16.3*.
- 8 **População** corresponde ao povo (brasileiros natos e naturalizados), juntamente com os estrangeiros e os apátridas. Deixamos claro que a proporcionalidade deve se dar em relação à **população**, e não ao número de eleitores.
- 9 Julgamento conjunto das **ADIs 4.947, 4.963, 4.965, 5.020, 5.028 e 5.130**, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, j. 01.07.2014, Plenário, *DJE* de 30.10.2014.
- 10 Muito embora o texto da Constituição fale em competência privativa, tecnicamente, melhor seria se tivesse dito **competência exclusiva**, em razão de sua **indelegabilidade**.
- 11 Muito embora o texto da Constituição fale em competência privativa, tecnicamente, melhor seria se tivesse dito **competência exclusiva**, em razão de sua **indelegabilidade**.
- 12 Em relação aos **Deputados**: <<http://www2.camara.leg.br/transparencia>>. Por sua vez, em relação aos **Senadores**: <<http://www.senado.gov.br/transparencia>>, acesso em: 02.02.2015.
- 13 **Art. 57, § 2.º**: “O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4.º, **57, § 7.º**, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I”.
- 14 Art. 32, § 3.º: “Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no **art. 27**”.
- 15 No tocante aos parlamentares estaduais, o STF já se posicionou: “o art. 57, § 7.º, do texto constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de **reprodução obrigatória** pelos Estados-membros por força do **art. 27, § 2.º**, da Carta Magna. A Constituição é expressa, no **art. 39, § 4.º**, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares” (**ADI 4.587**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.05.2014, Plenário, *DJE* de 18.06.2014).
- 16 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 449.
- 17 Texto consolidado na forma do art. 402 do *RISF* pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, publicado no Suplemento do *Diário do SF* de 02.02.2015.

18 O art. 74 do Regimento Interno do Senado Federal, só para dar um exemplo, estabelece que as **comissões temporárias** serão: a) **internas** — as previstas no Regimento para finalidade específica; b) **externas** — destinadas a representar o Senado em congressos, solenidades e outros atos públicos; c) **parlamentares de inquérito** — criadas nos termos da Constituição, art. 58, § 3.º. A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) será estudada em tópico separado.

19 Por exemplo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece que, no exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias; podendo convocar Ministros de Estado, tomar o **depoimento de qualquer autoridade**, **inquirir testemunhas**, sob compromisso, **ouvir indiciados**, **requisitar** de órgão público **informações** ou **documentos de qualquer natureza**, bem como **requerer** ao **Tribunal de Contas da União** a realização de **inspeções** e **auditorias** que entender necessárias. Confira, ainda, o art. 36 do *RICD*. Uma observação: falar-se em poder de investigação próprio de autoridade judicial é restringir a atuação das CPIs, lembrando que o direito brasileiro, diferente do italiano, que influenciou a regra sobre as CPIs, rege-se pelo sistema **acusatório**, e não inquisitório, na medida em que a atividade típica de investigação é atribuição da Polícia Judiciária, ligada ao Poder Executivo.

20 Conforme ponderou o Ministro Celso de Mello, “com a transmissão das informações pertinentes aos dados reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar de Inquérito — enquanto depositária desses elementos informativos — a nota de confidencialidade relativa aos registros sigilosos. Constitui conduta altamente censurável — com todas as consequências jurídicas (inclusive aquelas de ordem penal) que dela possam resultar — a transgressão, por qualquer membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, do dever jurídico de respeitar e de preservar o sigilo concernente aos dados a ela transmitidos. Havendo justa causa — e achando-se configurada a necessidade de revelar os dados sigilosos, seja no relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (como razão justificadora da adoção de medidas a serem implementadas pelo Poder Público), seja para efeito das comunicações destinadas ao Ministério Público ou a outros órgãos do Poder Público, para os fins a que se refere o art. 58, § 3.º, da Constituição, seja, ainda, por razões imperiosas ditadas pelo interesse social — a divulgação do segredo, precisamente porque legitimada pelos fins que a motivaram, não configurará situação de ilicitude, muito embora traduza providência revestida de **absoluto grau de excepcionalidade**” (MS 23.452/RJ, Min. Celso de Mello, *DJ* de 12.05.2000, p. 20, *Ement.* v. 1990-01, p. 86). *Vide*,

ainda, MS 23.880/DF, Min. Celso de Mello, *DJU* de 07.02.2001.

21 De acordo com o art. 192 da CF/88, o **sistema financeiro nacional**, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, **será regulado por leis complementares** que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

22 “A **condição de testemunha não afasta a garantia constitucional do direito ao silêncio** (CF, art. 5.º, LXIII: ‘o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado’). Com esse entendimento, o Tribunal, confirmando a liminar concedida, deferiu *habeas corpus* para assegurar ao paciente — inicialmente convocado à CPI do Narcotráfico como indiciado —, na eventualidade de retornar à CPI para prestar depoimento, **ainda que na condição de testemunha**, o direito de recusar-se a responder perguntas quando impliquem a possibilidade de **autoincriminação**. HC 79.589-DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, 05.04.2000” (*Inf. 184/STF* — original sem grifos).

23 “As Comissões Parlamentares de Inquérito **não podem determinar a busca e apreensão domiciliar**, por se tratar de ato sujeito ao **princípio constitucional da reserva de jurisdição**, ou seja, ato cuja prática a CF atribui com **exclusividade aos membros do Poder Judiciário** (CF, art. 5.º, XI: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’). Com base nesse entendimento, o Tribunal deferiu mandado de segurança contra ato da CPI do Narcotráfico que ordenara a busca e apreensão de documentos e computadores na residência e no escritório de advocacia do impetrante — para efeito da garantia do art. 5.º, XI, da CF, o conceito de casa abrange o local reservado ao exercício de atividade profissional —, para determinar a imediata devolução dos bens apreendidos, declarando ineficaz a eventual prova decorrente dessa apreensão. Ponderou-se, ainda, que o fato de ter havido autorização judicial para a perícia dos equipamentos apreendidos não afasta a ineficácia de tais provas, devido à ilegalidade da prévia apreensão. Precedente citado: MS 23.452-RJ (*DJU* 12.05.2000, v. Transcrições dos *Informativos* 151 e 163)” (*Inf. 212/STF*).

24 *Comissões Parlamentares de Inquérito*, Edições Paloma — Complexo Jurídico Damásio de Jesus, p. 24. Nesse sentido a jurisprudência do STF: “As Comissões

Parlamentares de Inquérito — CPI têm poderes de investigação vinculados à produção de elementos probatórios para apurar fatos certos e, portanto, **não podem decretar medidas assecuratórias para garantir a eficácia de eventual sentença condenatória (CPP, art. 125), uma vez que o poder geral de cautela de sentenças judiciais só pode ser exercido por juízes**. Com esse entendimento, o Tribunal deferiu mandado de segurança para tornar sem efeito ato do Presidente da chamada CPI dos Bancos que decretara a indisponibilidade dos bens dos impetrantes. Precedente citado: MS 23.452-DF (DJU de 8.6.99. Leia o inteiro teor da decisão na seção de Transcrições do *Informativo* 151). MS 23.446-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, 18.8.99” (*Inf. 158/STF*). *Vide*, também, *Inf. 170/STF*. Cf. **Lei n. 11.435, de 28.12.2006**, que altera os arts. 136, 137, 138, 139, 141 e 143 do CPP, para substituir a expressão “sequestro” por “arresto”, com os devidos ajustes redacionais.

25 E. P. de Oliveira, *Curso de processo penal*, 12. ed., p. 347.

26 *Elementos de direito constitucional*, p. 129.

27 Convém salientar, a título de curiosidade, que a referida **PEC** teve início no Senado Federal, sendo substancialmente alterada na Câmara dos Deputados. A nova redação dada pela CD foi aprovada em dois turnos no SF por unanimidade (74 votos em primeiro turno — 18.12.2001, e 67 votos em segundo turno — 19.12.2001), tendo sido promulgada em 20.12.2001. Assim, ao que se percebe, através do **Requerimento n. 758/2001**, de autoria do Senador Ramez Tebet, solicitando a dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do parecer sobre a matéria, foi alterado o calendário regimental de tramitação da **PEC**. Em virtude do novo regime, em 17.12.2001, o Senador Jefferson Péres (PDT-AM) ajuizou no STF o MS 24.154-3, com pedido de liminar, contra ato da Presidência do Senado Federal, alegando que os prazos regimentais de tramitação da PEC foram desrespeitados. O Ministro Relator Nelson Jobim negou seguimento ao referido MS entendendo tratar-se de matéria *interna corporis*, não podendo o Judiciário apreciá-la.

28 Nesse sentido posicionou-se o STF, analisando as novas regras da EC n. 35/2001, cf. **Inq. 1.710/DF**, Rel. Min. Sydney Sanches, *Inf. 258/STF*, 25.02.2002 a 1.º.03.2002.

29 Damásio assevera que o *caput* do art. 53 da CF/88 “... prevê a imunidade parlamentar material ou penal em relação aos denominados delitos de opinião, segundo a qual, aplicada a teoria da imputação objetiva, a conduta do Senador ou Deputado Federal, constitucionalmente permitida, e o resultado eventualmente produzido são atípicos” (Damásio de Jesus, *Imunidade parlamentar processual — nova trapalhada*

legislativa, São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, fev. 2002, disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>).

30 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, p. 371.

31 “A **imunidade material** prevista no art. 53, *caput*, da CF (‘Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos’) **alcança a responsabilidade civil decorrente dos atos praticados por parlamentares no exercício de suas funções**. É necessário, entretanto, analisar-se caso a caso as circunstâncias dos atos questionados para verificar a **relação de pertinência com a atividade parlamentar**. Com esse entendimento, o Tribunal deu provimento a recurso extraordinário para restabelecer a sentença de 1.º grau que, nos autos de **ação de indenização por danos morais** movida contra deputada federal, determinara a extinção do processo sem julgamento de mérito devido à vinculação existente entre o ato praticado e a função parlamentar de fiscalizar o poder público (tratava-se, na espécie, de divulgação jornalística da *notitia criminis* apresentada pela deputada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra juiz estadual por suposto envolvimento em fraude no INSS)” (RE 210.917-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.08.1998, *Inf. 118/STF*, 10 a 14.08.1998).

32 Nesse sentido, só para ilustrar, lembramos o art. 4.º do Regimento Interno do Senado Federal, que estabelece: “a **posse, ato público através do qual o Senador se investe no mandato**, realizar-se-á perante o Senado, durante reunião preparatória, sessão ordinária ou extraordinária, **precedida da apresentação à Mesa do diploma expedido pela Justiça Eleitoral**, o qual será publicado no *Diário do Congresso Nacional*” (destacamos).

33 **Art. 5.º, LXV, da CF/88**: “a prisão **ilegal** será imediatamente **relaxada** pela autoridade judiciária”.

34 **Art. 310 do CPP**: “Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I — relaxar a prisão ilegal; ou II — converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III — conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

35 O Plenário do STF pacificou o entendimento de que a execução da pena privativa de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, contraria o art. 5.º, LVII, da Constituição, só podendo, nessa hipótese, a prisão ser decretada a título cautelar (**HC 84.078**, Rel. Min. Eros Grau, j. 05.02.2009, Plenário, *DJE* de 26.02.2010). No julgamento

do mensalão, contudo, conforme explicamos nas linhas seguintes, a Corte admitiu a certificação de **trânsito em julgado parcial do acórdão**, por capítulos, nas partes não questionadas ou contra as quais não mais se admitissem recursos, podendo, nesses pontos, a execução da pena ser **imediata**, com a consequente expedição de mandado de prisão e lançamento do nome dos réus no rol dos culpados (**AP 470**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, Plenário, *DJE* de 22.04.2013).

36 Para aprofundamento, remetemos o nosso querido leitor para o *item 9.11.4*.

37 **AP 470**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, Plenário, *DJE* de 22.04.2013.

38 Cabe alertar que, a partir do advento das **Leis ns. 11.689/2008** e **11.719/2008**, as outras duas modalidades de *prisão cautelar* previstas na redação original do Código de Processo Penal, quais sejam, a *prisão por sentença condenatória recorrível* (art. 393, I, do CPP, revogado) e a *prisão por pronúncia* (art. 585 do CPP, revogado) **deixaram de existir**. Nesse sentido, reforça o **art. 283 do CPP**, na redação dada pela **Lei n. 12.403/2011**: “Ninguém poderá ser preso senão em **flagrante delito** ou por *ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente*, em decorrência de **sentença condenatória transitada em julgado** ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de **prisão temporária** ou **prisão preventiva**”.

39 Art. 5.º, LXVII — “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de **obrigação alimentícia** e a do **depositário infiel**”. Cabe alertar que o STF entende não mais cabível a prisão civil do depositário infiel (Pacto de São José da Costa Rica — tese da **supralegalidade** — cf. discussão no *item 9.14.5.2.3* e **SV n. 25/2009-STF**: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”).

40 Confirmam-se os incisos XLII, XLIII e XLIV do art. 5.º da CF/88: “XLII — a prática do **racismo** constitui **crime inafiançável** e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII — a **lei** considerará **crimes inafiançáveis** e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da **tortura**, o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **terrorismo** e os **definidos como crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV — constitui crime **inafiançável** e imprescritível a **ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**” (destacamos).

41 Nesse sentido, harmonizando as duas disposições, cf. José Afonso da Silva, *Curso de*

direito constitucional positivo, 20. ed., p. 533.

42 Nesse sentido, o posicionamento do STF, interpretando as novas regras da EC n. 35/2001, de **aplicação imediata**, inclusive aos casos de licenças negadas na vigência do regime anterior: “Tendo em conta que com a superveniência da EC 35/2001 ficou eliminada a exigência de licença prévia da Casa respectiva para instauração de processos contra membros do Congresso Nacional por fatos **não cobertos pela imunidade material**, o Tribunal, resolvendo questão de ordem, e dando pela aplicabilidade imediata da referida norma aos casos pendentes, declarou prejudicado o pedido de licença prévia para o prosseguimento de ação penal proposta contra deputado federal e, em consequência, determinou o término da suspensão do curso da prescrição dos fatos a ele imputados, a partir da publicação da mencionada emenda. O Tribunal declarou, ainda, a validade do oferecimento da denúncia e da notificação para defesa prévia, praticados anteriormente à posse do indiciado no cargo de Deputado Federal pelo juízo então competente...” (**Inq. 1.566/AC**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *Inf. 257/STF*, 18 a 22.02.2002). Nesse sentido, cf., ainda, **Inf. 265 e 266/STF**.

43 **Súmula 394: Cancelamento.** Concluído o julgamento de questão de ordem na qual se discute o cancelamento ou a revisão da Súmula 394 do STF (“Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”) (*vide Inf. 149 e 69/STF*). O Tribunal, por unanimidade, cancelou a Súmula 394 por entender que o art. 102, I, “b”, da CF — que estabelece a competência do STF para processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o procurador-geral da República — não alcança aquelas pessoas que não mais exercem mandato ou cargo. Após, o Tribunal, por maioria, rejeitou a proposta do Ministro Sepúlveda Pertence para a edição de nova súmula ao dizer que, “cometido o crime no exercício do cargo ou a pretexto de exercê-lo, prevalece a competência por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício funcional”. Vencidos, nesse ponto, os Ministros Nelson Jobim, Ilmar Galvão e Néri da Silveira, que o acompanhavam para acolher a proposta de edição de nova súmula. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, decidiu que continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas com base na Súmula 394 do STF, é dizer, a decisão tem efeito *ex nunc*. Em consequência, o Tribunal resolveu a questão de ordem dando pela incompetência originária do STF e determinou a remessa dos autos à Justiça de primeiro

grau competente. Leia em Transcrições a íntegra do voto do Ministro Sydney Sanches, relator. Inq. 687-SP (QO) e Inq. 881-MT (QO), Rel. Min. Sydney Sanches; AP 313-DF (QO), AP 315-DF (QO), AP 319-DF (QO) e Inq. 656-AC (QO), Rel. Min. Moreira Alves, 25.08.1999 (*Inf. 159/STF*, Brasília, 23 a 27.08.1999).

44 CUIDADO: o nosso ilustre leitor deve ficar atento ao julgamento da **PET 3.240 AgR** (*pendente*), na qual dois importantes temas estão sendo rediscutidos: a) duplo regime; b) prerrogativa de foro (cf. *item 10.4.15.5*).

45 *Notícias STF*, 28.10.2010 — publicado o acórdão (**AP 396**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.10.2010, Plenário, *DJE* de 28.04.2011), houve a interposição de embargos de declaração, rejeitados por unanimidade em 13.12.2012, *DJE* de 08.02.2013. Interpostos segundos embargos, também não foram conhecidos e, em 26.06.2013, certificou-se o trânsito em julgado, expedindo-se o competente mandado de prisão (**AP 396-ED-ED**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.6.2013, Plenário, *DJE* de 30.09.2013).

46 Interessante anotar que o STF, em 15.08.2012, **acolheu** preliminar de **cerceamento de defesa** suscitada pelo Defensoria Pública Federal pela falta de intimação de advogado constituído, anulando o processo a partir da defesa prévia e determinando o **desmembramento** do feito, com a remessa dos autos para a justiça de primeira instância, para dar andamento à persecução penal (*Inf. 675/STF*).

47 Deve-se deixar claro que estamos falando em *cassação do mandato*, e não em *cassação de direitos políticos*, esta expressamente inadmitida na Constituição, cujo art. 15 prescreve somente as hipóteses de *perda* ou de *suspensão* de *direitos políticos*.

48 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 8. ed., p. 429.

49 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 8. ed., p. 429.

50 Sobre o assunto, sugerimos **vídeo** por nós gravado à época dos fatos, em 03.09.2013, devendo ser atualizado com a informação da aprovação da “PEC do voto aberto”, promulgada como **EC n. 76/2013: Perda do Mandato Parlamentar — caso Natan Donadon — Mensalão — PEC do Voto Aberto**, em nossa página: <<https://www.youtube.com/pedrolenzaoficial>>.

51 A discussão surgiu em relação aos **parlamentares federais**. Houve **unanimidade** no sentido da decretação da perda de mandato eletivo do réu que exercia mandato de prefeito (José Borba, então prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná). Dessa forma, ficou estabelecido que a regra da **cassação imediata de mandatos** incide, por inteiro, em

relação aos ocupantes dos cargos eletivos do Executivo: Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, bem como os Prefeitos.

52 Art. 92 do CP: “São também efeitos da condenação: I — a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: *a)* quando aplicada **pena privativa de liberdade** por tempo **igual** ou **superior a 1 (um) ano**, nos **crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública**; *b)* quando for aplicada **pena privativa de liberdade** por tempo **superior a 4 (quatro) anos** nos demais casos; (...) Parágrafo único. Os **efeitos** de que trata este artigo **não são automáticos**, devendo ser **motivadamente declarados na sentença**”.

53 Cf. *Ata da 224.^a Sessão da Assembleia Nacional Constituinte*, em 14.03.1988, publicada em 15.03.1988, p. 215-216 <<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituente/N015.pdf>>.

54 Registraram-se 233 votos pela cassação, 131 pela manutenção e 41 abstenções, faltando, assim, 24 votos para a perda do mandato. Curiosamente, apesar de registrada a presença de quase 460 deputados, apenas 405 votaram, muitos se retirando do plenário de votação! Conforme decidiu o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, “tendo em vista a rejeição do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que opinava pela procedência da Representação, esta Presidência dará consequência à decisão do Plenário. Todavia, uma vez que, **em razão do cumprimento da pena em regime fechado**, o Deputado Natan Donadon encontra-se impossibilitado de desempenhar suas funções, considero-o afastado do exercício do mandato e determino a convocação do suplente imediato, em caráter de substituição, pelo tempo que durar o impedimento do titular. Acrescente-se que a representação da Câmara dos Deputados não pode permanecer desfalcada indefinidamente, assim como a sociedade e o Estado de Rondônia não podem ficar privados de um de seus representantes” (<<http://www2.camara.leg.br/a-camara/presidencia/noticias/presidente-convoca-suplente-do-deputado-natan-donadon>>, acesso em 02.02.2014).

55 “O deputado afastado de suas funções para exercer cargo no Poder Executivo não tem imunidade parlamentar. Com esse entendimento, a Turma indeferiu *habeas corpus* em que se pretendia o trancamento da ação penal instaurada contra deputado estadual que, à época dos fatos narrados na denúncia, encontrava-se investido no cargo de secretário de estado. Precedente citado: Inquérito 104-RS (*RTJ* 99/477). HC 78.093-AM, Rel. Min. Octavio Gallotti, 11.12.98” (*Inf. 135/STF*).

56 **MS 25.579-MC**, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, j. 19.10.2005, Plenário, *DJ* de 24.08.2007. Em **18.02.2010**, referido MS foi julgado **extinto**, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de objeto, já que o então parlamentar, licenciado para o exercício do cargo de Ministro da Casa Civil, na medida em que a liminar fora indeferida, teve o seu mandato cassado, pelo plenário da Câmara. Além disso, com o fim da 52.^a *Legislatura da Câmara dos Deputados*, o mandato foi, também, definitivamente extinto.

57 José Afonso da Silva define o **processo legislativo** como “um conjunto de atos preordenados visando à criação de normas de direito. Esses atos são: *a*) iniciativa legislativa; *b*) emendas; *c*) votação; *d*) sanção e veto; *e*) promulgação e publicação” (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 458).

58 Como exemplo, destacamos a **Lei n. 12.918/2013**, de **iniciativa da Presidente Dilma Rousseff**, que modificou os efetivos do Exército (art. 142), em tempo de paz.

59 Alínea “c” com redação determinada pela EC n. 18/98.

60 Apesar de essa matéria (art. 61, § 1.º, II, “d”) ter sido definida como hipótese de competência privativa do **Presidente da República**, o constituinte originário de 1988 estabeleceu exceção a essa regra, no art. 128, § 5.º, em que atribuiu competência concorrente também ao **Procurador-Geral da República** para dispor sobre a **organização do Ministério Público da União**, como apontaremos adiante no item 9.13.3.7.1.

61 Alínea “f” acrescentada pela EC n. 18/98.

62 Nesse sentido, “... tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua...” (ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves, j. 11.03.1999, *DJ* de 14.04.2000). Cf., também, ADI 2.734-MC/ES, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2003, e ADI 106-RO, Rel. orig. Min. Carlos Velloso, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2002 (*Inf. 285/STF*).

63 Cf. os seguintes precedentes: ADI 766-MC/RS (*DJU* de 25.05.1994); ADI 822/RS (*DJU* de 06.06.1997); ADI 805/RS (*DJU* de 12.03.1999); ADI 2.322-MC/AL, Rel. Min. Moreira Alves, j. 23.05.2001; ADI 1.954/RO, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 27.05.2004; ADI 2.079, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 29.04.2004, *DJ* de 18.06.2004.

64 Cf. ADI 1.070-MC, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 15.09.1995; e ADI 700, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23.05.2001, *DJ* de 24.08.2001.

- 65 “Regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Aposentadoria e vantagens financeiras. **Inconstitucionalidade formal. Vício que persiste, não obstante a sanção do respectivo projeto de lei.** Precedentes. Dispositivo legal oriundo de emenda parlamentar referente aos servidores públicos estaduais, sua aposentadoria e vantagens financeiras. Inconstitucionalidade formal em face do disposto no artigo 61, § 1.º, II, ‘c’, da Carta Federal. **É firme na jurisprudência do Tribunal que a sanção do projeto de lei não convalida o defeito de iniciativa**” (ADI 700, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23.05.2001, *DJ* de 24.08.2001). Nesse sentido, cf., ainda: ADI 2.417, Rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 05.12.2003, e ADI 1.963-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 07.05.1999.
- 66 O art. 13 da Lei n. 9.709/98, que regulamentou o art. 14 da CF/88, em seus parágrafos estabelece que o **projeto de lei de iniciativa popular** deverá circunscrever-se a um só assunto, não podendo ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. Por fim, o art. 14 dispõe que, sendo verificado pela Câmara dos Deputados o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo anterior (art. 13) e respectivos parágrafos, será dado seguimento à iniciativa popular, consoante as normas do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
- 67 Nada mais natural que a apresentação do aludido projeto de lei à Câmara dos Deputados, onde se concentram os representantes do povo, de acordo com o art. 45, *caput*.
- 68 Cf. discussão sobre iniciativa popular em PEC, em matérias de iniciativa reservada e outros detalhes abaixo.
- 69 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Do processo legislativo*, p. 203.
- 70 Para uma análise mais aprofundada do assunto, cf. o completíssimo *Direito eleitoral brasileiro*, 3. ed., de Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, p. 1147 e s.
- 71 “Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e **cassação do registro ou do diploma**, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990.”

- 72 Cf. <www.cidades.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=498&Itemid=0>.
- 73 Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, *Processo legislativo*, p. 207.
- 74 Mônica de Melo, *Plebiscito, referendo e iniciativa popular: mecanismos constitucionais de participação popular*, p. 194.
- 75 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 24. ed., p. 64.
- 76 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 24. ed., p. 63.
- 77 *Notícias STF*, 09.08.2005; <www.alepa.pa.gov.br/noticias2.asp?cod=626>; cf., ainda, o art. 8.º, parágrafo único, da Constituição do Estado do Pará.
- 78 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 295.
- 79 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 449.
- 80 Convém lembrar que o art. 2.º da **Lei n. 11.143/2005**, ao modificar o *caput* do art. 2.º da Lei n. 8.350/91, estabeleceu que, a partir de 1.º de janeiro de 2005, a gratificação mensal de Juízes Eleitorais corresponderá a 18% do subsídio de Juiz Federal. O art. 3.º da Lei n. 11.143/2005, por sua vez, fixou que, a partir de 1.º de janeiro de 2006, a gratificação mensal de Juízes Eleitorais corresponderá a 16% do subsídio de Juiz Federal.
- 81 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 449.
- 82 “A atribuição, exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo estadual, da iniciativa do projeto de Lei Orgânica do Ministério Público, por sua vez, configura violação ao art. 128, § 5.º, da Constituição Federal, que faculta tal prerrogativa aos Procuradores-Gerais de Justiça” (ADI 852, Rel. Min. Ilmar Galvão, *DJ* de 18.10.2002).
- 83 “... Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É que esse — porque compreendido no Ministério Público da União (CF, art. 128, ‘d’) — se insere, nessa condição, no campo normativo da **lei complementar federal** que estabelecerá ‘a organização, as atribuições e o estatuto’ de todo o Ministério da União — por iniciativa **concorrente** do **Procurador-Geral da República**, que lhe chefia o conjunto de ramos (CF, art. 128, § 1.º) e do **Presidente da República** (CF, art. 61, § 1.º, II, ‘d’, primeira parte); simultaneamente, contudo, na parte final dessa alínea ‘d’, a Carta Fundamental previu a edição, mediante iniciativa privativa do Presidente da República, de ‘normas gerais para a organização’, não só ‘do Ministério Público dos Estados’, mas também do mesmo ‘Ministério Público do Distrito Federal e Territórios’” (RE 262.178, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, voto, *DJ* de 24.11.2000).

⁸⁴ Em relação a estes dois últimos assuntos, cf. ADI 2.010-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.09.1999, *DJ* de 12.04.2002.

⁸⁵ *Direito constitucional*, 9. ed., p. 513.

⁸⁶ P. A. Casseb, *Processo legislativo: atuação das comissões permanentes e temporárias*, p. 322-323.

⁸⁷ Referida **Res. n. 47/2013** inseriu o inciso V ao § 2.º do art. 188, *RICD*, para deixar explícita a vedação de escrutínio secreto na **deliberação** sobre a decretação de perda de mandato nas hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal. Com o máximo respeito, se há proibição de **deliberação** por escrutínio secreto, no mesmo sentido, deveria haver proibição de **pronunciamento** sobre a perda do mandato por escrutínio secreto. Nesse caso, para que houvesse adequação à **EC n. 76/2013**, entendemos que a votação deveria ser ostensiva (aberta) para essa hipótese do art. 188, IV, do *RICD* (*alteração regimental pendente*).

⁸⁸ Esgotado sem deliberação o referido prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final (cf. art. 66, § 6.º, na redação determinada pela **EC n. 32/2001**).

⁸⁹ **Art. 104 do RICN**: “Comunicado o veto ao Presidente do Senado, este convocará sessão conjunta, a realizar-se dentro de 72 (setenta e duas) horas, para dar conhecimento da matéria ao Congresso Nacional, designação da **Comissão Mista** que deverá relatá-lo e estabelecimento do calendário de sua tramitação. § 1.º O prazo de que trata o § 4.º do art. 66 da Constituição será contado a partir da sessão convocada para conhecimento da matéria. § 2.º A Comissão será composta de 3 (três) Senadores e 3 (três) Deputados, indicados pelos Presidentes das respectivas Câmaras, integrando-a, se possível, os Relatores da matéria na fase de elaboração do projeto”.

⁹⁰ **Art. 105 do RICN**: “A Comissão Mista terá o prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua constituição, para apresentar seu relatório”.

⁹¹ M. G. Ferreira Filho, *Do processo legislativo*, 6. ed., p. 156-158.

⁹² J. A. da Silva, *Processo constitucional de formação das leis*, p. 219.

⁹³ *Curso de direito constitucional positivo*, p. 461.

⁹⁴ Conforme já alertamos em outra passagem desta obra, o *Decreto-lei n. 4.657/42*

introduziu em nosso ordenamento a então denominada *LICC — Lei de Introdução ao Código Civil*, que, à época, já extrapolava o direito civil, seja por regular a validade, eficácia, vigência, interpretação, revogação das normas, seja por definir conceitos amplos, como o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, seja, de modo geral, por apresentar um inegável caráter universal, aplicando-se aos demais “ramos” do direito. Por esse motivo, a **Lei n. 12.376/2010** passou a denominá-la **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)**, mantendo intacto o seu conteúdo. Conforme observa Carlos Roberto Gonçalves, “trata-se de um conjunto de **normas sobre normas**, visto que disciplina as próprias normas jurídicas, determinando o seu modo de aplicação e entendimento no tempo e no espaço. Ultrapassa ela o âmbito do direito civil, pois enquanto o **objeto** das leis em geral é o comportamento humano, o da Lei de Introdução é a **própria norma**, visto que disciplina a sua elaboração e vigência, a sua aplicação no tempo e no espaço, as suas fontes etc. Contém normas de **sobredireito** ou de apoio, sendo considerada um **Código de Normas**, por ter a lei como tema central” (*Direito civil esquematizado*, v. 1, 2012, p. 53).

95 *Elementos de direito constitucional*, p. 144.

96 Em relação à reforma no âmbito estadual, assim manifestou o STF: “processo de reforma da Constituição estadual — Necessária observância dos requisitos estabelecidos na CF (art. 60, §§ 1.º a § 5.º) — **Impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa** — Exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo local — A questão da autonomia dos Estados-membros (CF, art. 25) — Subordinação jurídica do poder constituinte decorrente às limitações que o órgão investido de funções constituintes primárias ou originárias estabeleceu no texto da Constituição da República (...)” (**ADI 486**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.04.1997, Plenário, *DJ* de 10.11.2006).

97 André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves, *Direito penal esquematizado*: parte geral, 3. ed., p. 115-116.

98 Jorge Miranda, *Manual de direito constitucional*, p. 181 e s.

99 Verificar interessante estudo em “Significação e alcance das ‘cláusulas pétreas’” (*RDA* 202/11-17, out./dez. 1995), defendendo a teoria da **dupla revisão**, especialmente por entender que o constituinte de 1987/1988 foi investido de poderes especiais por força da

Emenda n. 26/85 à Constituição de 1967. Confira, ainda, Manoel G. Ferreira Filho, *Do processo legislativo*, cit., p. 145.

100 Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, 19. ed., p. 145.

101 Obs.: a doutrina prefere a utilização da nomenclatura **maioria simples** a **maioria relativa**.

102 Precisa a explicação do Ministro Luiz Gallotti, ao relatar acórdão proferido pelo Pleno do STF em 26.11.1969: “Ementa: (...) Maioria Absoluta. Sua definição, como significando **metade mais um**, serve perfeitamente quando o total é **número par**. Fora daí, temos que recorrer à **verdadeira definição**, a qual, como advertem Scialoja e outros, deve ser esta, que serve, **seja par ou ímpar o total: maioria absoluta é o número imediatamente superior à metade**. Assim, maioria absoluta de quinze são oito, do mesmo modo que, de onze (número de Juízes do Supremo Tribunal), são seis, e sobre isso não se questiona nem se duvida aqui...” (RE 68.419/MA, Rel. Min. Luiz Gallotti, *DJ* de 15.05.1970, p. 1981, *RF* 235/72, Tribunal Pleno).

103 Conforme estabelece o art. 46, § 1.º, cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores. Como existem 26 Estados-Membros e o Distrito Federal, então $(26 + 1) \times 3 = 81$.

104 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 46. Nesse particular agradeço ao *Professor Jorge Hélio Chaves de Oliveira*, de Fortaleza, pela sugestão em fazer essa importante ressalva.

105 Cf. Sergio Reginaldo Bacha, *Constituição Federal: leis complementares e leis ordinárias — hierarquia?*, passim.

106 *Direito constitucional*, p. 511-512.

107 *Direito constitucional*, p. 148.

108 Cf. ADI 748-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.07.1992, Plenário, *DJ* de 06.11.1992. O efeito de eventual controle judicial de constitucionalidade por meio de ADI, por outro lado, produziria, por regra, efeito *ex tunc*, em razão da declaração de **nulidade** do ato normativo, qual seja, a lei delegada.

109 M. G. Ferreira Filho, *Do processo legislativo*, 6. ed., p. 236.

110 Para se ter ideia, na vigência da CF/88 foram elaboradas apenas duas leis delegadas, quais sejam, as de ns. **12** e **13**, respectivamente datadas de 07.08.1992 e 27.08.1992.

111 O art. 25, § 2.º, do ADCT estabelece: “Os decretos-leis editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no art. 62, parágrafo único”.

112 Michel Temer, *Elementos de direito constitucional*, p. 151-152 (grifamos).

113 Pinto Ferreira, nesse sentido, com propriedade observa que “as **medidas provisórias** são **mais específicas do regime parlamentarista**, em que o gabinete é uma dependência do corpo legislativo, podendo tal gabinete **cair em face de desacordo com este**. No regime presidencialista, o chefe do Executivo não está sujeito a censura que provoque a sua demissão, e assim a **medida provisória é uma forma de concentração do poder no Executivo**” (*Curso de direito constitucional*, p. 337 — grifamos). Nesse mesmo sentido, Bulos observa que “o tempo mostrou que a realidade italiana diverge da brasileira. Na Itália, o sistema de governo é o parlamentar. Quando ocorrem crises legislativas, o modo de solucioná-las é dissolver a Câmara dos Deputados ou promover a queda do Gabinete. Nesse país, tais crises são desencadeadas pelo impasse entre o Executivo e o Legislativo, motivando rejeições, como aquela que provocou a derrocada de um dos gabinetes do Primeiro-Ministro Fanfani. **Dai a medida provisória ajustar-se às Conveniências do Parlamentarismo, jamais ao sistema presidencial**. Nos países de estrutura parlamentar, como a Alemanha, a França e a Itália, a espécie normativa participa de um contexto político-constitucional diverso do brasileiro” (Uadi Lammêgo Bulos, *Constituição federal anotada*, p. 737 — grifamos).

114 Conforme recorda José Afonso da Silva, “as *medidas provisórias* não constavam da enumeração do art. 59 como objeto do processo legislativo, e não tinham mesmo que constar, porque sua formação não se dá por processo legislativo. São simplesmente editadas pelo Presidente da República. A redação final da Constituição não as trazia nessa enumeração. Um gênio qualquer, de mau gosto, ignorante, e abusado, introduziu-as aí, indevidamente, entre a aprovação do texto final (portanto depois do dia 22.9.88) e a promulgação-publicação da Constituição no dia 5.10.88” (*Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 524).

115 Em rigorosa crítica, Márcia Maria Corrêa de Azevedo observa que “as medidas provisórias representam o câncer que consome, lenta e gradualmente, a saúde de nossa democracia. Como o vírus maligno, de fora, estranho, que veio instalar-se num organismo já meio fraco, debilitado, encontrando então ambiente apropriado para desenvolver-se, modificar o núcleo de células sadias, alterando a estrutura do *DNA*, reproduzindo-se de

modo descontrolado e violento, ocupando todo o espaço da vida sadia, da normalidade. Tem até nome de vírus — *provvedimenti provvisori (com (sic) forza di lege)*” (*Prática do processo legislativo*, p. 178).

116 Discurso do Senador Romero Jucá quando da votação da PEC n. 1-B/95, *DSF*, 06.09.2001, p. 20956.

117 **S. 651/STF**: “A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a EC n. 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição”.

118 Roque Antonio Carrazza, com a perspicácia de sempre, entende inadmissível a reedição de medida provisória, em qualquer hipótese, havendo ou não expressa rejeição pelo Congresso Nacional. Isso porque, “... do contrário, estaríamos aceitando, em detrimento do princípio da tripartição das funções do Estado, que o Presidente da República, por meio da reiteração de medidas provisórias, pode, a seu critério, legislar, passando ao largo do Congresso Nacional. Depois, os próprios requisitos de urgência e relevância desapareceriam, na prática...” (*Curso de direito constitucional tributário*, 16. ed., p. 243 e nota 37). Entendendo inadmissível a MP em qualquer hipótese, cf., ainda, Hugo de Brito Machado, Efeitos da medida provisória rejeitada, *RT* 700/46, e Paulo de Barros Carvalho, *Curso de direito tributário*, 13. ed., p. 64. Sobre o posicionamento do STF, admitindo a reedição da MP, desde que não haja expressa rejeição pelo CN (**rejeição tácita**), cf. ADI 1.250-9/DF, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* 1, de 06.09.1995, p. 28252; ADI 293-7/600/DF, Pleno, medida liminar, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e ADI 295-3, Rel. Min. Carlos Velloso.

119 Desde que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas do DF e Municípios reproduzam todas as diretrizes básicas fixadas na CF/88 sobre o processo legislativo das medidas provisórias (STF, Pleno, ADI 822-MC/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 12.03.1993, p. 3557, *Ement.* v. 01695-02, p. 243), entendemos possível a edição de MPs pelos chefes dos Executivos estaduais, distrital e municipais. Cf. STF, Pleno, ADI 812-9/TO, na qual o relator, Ministro Moreira Alves, reconhece a inexistência de “... proibição de os Estados-membros adotarem a figura da medida provisória...”. Cf., ainda, de maneira expressa e consagrando o posicionamento pela possibilidade de adoção pelos Chefes do Executivo, desde que se respeitem as regras federais, pelo princípio da simetria, bem como a necessidade de expressa previsão nas Constituições estaduais e leis orgânicas, **ADI 2.391/SC**, Rel. Min. Ellen Gracie, 16.08.2006 (*Inf.* 436/STF). Conforme *Notícias STF*, 16.08.2006 — 19h10, “Ellen Gracie citou o voto do relator da ADI n. 425, ministro

Maurício Corrêa (aposentado), ao afirmar que o § 1.º, do art. 25, da Constituição Federal reservou aos Estados ‘as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição’. Quis o constituinte que as unidades federadas pudessem adotar o modelo do processo legislativo admitido para a União, uma vez que nada está disposto, no ponto, que lhes seja vedado”. Na doutrina, cf. Roque Carrazza, *Curso de direito constitucional tributário*, p. 240, nota 34.

120 Como observa Alexandre de Moraes, fundando-se em posicionamento da Corte Suprema, “... os requisitos de *relevância* e *urgência*, em regra, somente deverão ser analisados, primeiramente, pelo próprio Presidente da República, no momento da edição da medida provisória, e, posteriormente, pelo Congresso Nacional, que poderá deixar de convertê-la em lei, por ausência dos pressupostos constitucionais. Excepcionalmente, porém, quando presente desvio de finalidade ou abuso de poder de legislar, por flagrante inobservância da urgência e relevância, poderá o Poder Judiciário adentrar a esfera discricionária do Presidente da República, garantindo-se a supremacia constitucional” (*Direito constitucional*, 9. ed., p. 540). Cf.: STF, Pleno, ADI 162-MC/DF (*DJU* de 19.09.1997), ADI 1.753-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 16.04.1998 etc. Sobre o controle jurisdicional, cf. *itens* 6.7.1.2.5, 6.7.1.2.10 e 6.7.1.2.16.

121 De acordo com o art. 20 da **Res. n. 1/2002-CN**, às MPs em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional n. 32, de 2001, aplicar-se-ão os procedimentos previstos na Resolução n. 1, de 1989-CN.

122 O que se pode entender da redação é que os 60 dias contam-se após a **rejeição expressa**, ou **perda da eficácia da MP**. Neste último caso, como a MP só perde a eficácia após 120 dias (60 dias prorrogáveis por mais 60 dias), a referida regra só valerá após **180 dias** (120 dias para perda da eficácia somados aos novos 60 dias). No primeiro caso, o prazo de 60 dias conta-se da **rejeição expressa**, durante o prazo de 120 dias.

123 Como disse Michel Temer, “a edição da medida provisória **paralisa temporariamente a eficácia da lei que versava a mesma matéria**. Se a medida provisória for aprovada, se opera a revogação. Se, entretanto, a medida provisória for rejeitada, restaura-se a eficácia da norma anterior. Isto porque, com a rejeição, o Legislativo expediu ato volitivo consistente em repudiar o conteúdo daquela medida provisória, tornando subsistente anterior vontade manifestada de que resultou a lei antes editada” (*Elementos de direito constitucional*, p. 153).

124 A título de exemplo, a primeira medida provisória editada após o advento das novas

regras trazidas pela **EC n. 32, de 11.09.2001**, foi a **MP n. 1, de 19.09.2001**, abrindo crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R\$ 154.000.000,00, nos termos do art. 167, § 3.º, citado. Como se percebe, as medidas provisórias após a EC n. 32/2001 vêm recebendo um novo número, iniciando-se pela acima referida, de n. 1, em ordem crescente, para se diferenciarem das MPs em tramitação e produzidas antes da novel emenda.

125 Cf. *itens* 6.7.1.2.5, 6.7.1.2.10 e 6.7.1.2.16.

126 Em dois julgamentos (**ADI 4.048** e **ADI 4.046**), houve entendimento no sentido da **prejudicialidade** das ações por **perda superveniente do objeto**. Isso porque, nos termos do art. 167, § 2.º, os créditos extraordinários abertos ou já tinham sido utilizados ou perderam a sua vigência. De todo modo, podemos afirmar a mudança da orientação da Corte de acordo com os julgamentos proferidos nas cautelares, no sentido de se permitir o controle judicial dos requisitos das medidas provisórias que abrem crédito extraordinário.

127 Apenas para se ter um exemplo em nosso passado, lembramos a MP n. 168, de 15.03.1990 (**Plano Collor**).

128 José Afonso da Silva é expresso ao dizer que o Presidente da República não poderá regulamentar matéria tributária através de MP “... porque o sistema tributário não permite legislação de urgência, já que a lei tributária material não é aplicável imediatamente, por regra, porquanto está sujeita ao princípio da anterioridade (art. 150, III, ‘b’)” (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 465).

Em argumentação bastante sedutora e completa, o Professor Roque Carrazza declara inadmitir a utilização das MPs para criar ou aumentar tributos, cabendo tal tarefa somente à lei ordinária e, em poucos casos, à complementar. A medida provisória, segundo o ilustre jurista, “... brota de chofre, no silêncio dos gabinetes, da vontade isolada e, por vezes, *imperial* do Chefe do Executivo. Se porventura, medida provisória pudesse criar ou aumentar tributos, que seria da *estrita legalidade*, da *segurança jurídica*, da *não surpresa* dos contribuintes?” (*Curso de direito constitucional tributário*, p. 255-256). No entanto, muito embora entendamos ser incabível a criação ou o aumento de tributos por MP, orientamos os candidatos para que **adotem a posição do STF**, agora corroborada no **art. 62, § 2.º, da CF/88**.

129 Cf.: ADI 1.667-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, *DJ* de 21.11.1997, p. 60586, ADI 1.135-9/DF, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 05.12.1997, p. 63903. E, ainda, RE 146.733-SP; RE 138.284-CE; RE 197.790-MG e RE 181.664-RS, RE 232.805-

MG, Rel. Min. Maurício Corrêa; RE 236.885-BA, Rel. Min. Sydney Sanches; RE 247.235-MG, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 266.752-RN, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 267.285-MG, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 269.423-BA, Rel. Min. Nelson Jobim, ADI 1.417-MC etc.

130 Art. 21, XI: "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais".

131 O Senador Roberto Requião observa, tecendo severas críticas ao aludido dispositivo: "como este Congresso não tem capacidade física, e a maioria do Governo pode obstruir, com a facilidade com que obstrui — quando deseja — a tramitação no Congresso, isso significa que essas medidas todas prolatadas até a publicação desse diploma legislativo que estamos discutindo estão automaticamente eternizadas, perenizadas, sem que o Congresso possa estabelecer, como disse o Senador Amir Lando, a sua capacidade de ser um contrapeso do processo..." (DSF de 06.09.2001, p. 20963).

132 Para as provas, sugerimos uma leitura atenta dos referidos incisos.

133 Flávia Piovesan, *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*, p. 77.

134 Diferentemente do Brasil, é interessante lembrar alguns Estados nos quais a prerrogativa de decidir definitivamente sobre tratados internacionais atribuída ao Parlamento fica condicionada à aprovação do povo (participação popular por intermédio do processo), através do plebiscito ou *referendum*. Como exemplo, ressalta-se a União Europeia, quando da elaboração do **Tratado de Maastricht**.

135 Deve-se deixar bem claro que o instrumento da **ratificação** tem sentido técnico entre os internacionalistas, indicando, perante a comunidade internacional, que o País aceita as regras fixadas no tratado internacional, obrigando-se aos seus vetores. Muitas vezes, o ato do Congresso Nacional, prévio, de **referendo, aprovação** do instrumento assinado, é também denominado **ratificação**, devendo o candidato ficar atento nas provas e concursos para saber de qual dos institutos a questão está tratando. Cuida-se de ratificação *lato sensu*, no sentido de confirmação do ato pelo Parlamento. Não tem o sentido técnico empregado pela doutrina internacionalista. Cf. interessante descrição da sistemática de incorporação dos tratados internacionais no ordenamento brasileiro em Valério de Oliveira Mazzuoli, *Direitos humanos & relações internacionais*, p. 65 e s., e *Tratados internacionais*, p. 37 e s.

- 136 Mirtô Fraga, *O conflito entre tratado internacional e a norma de direito interno*, p. 69.
- 137 Esse entendimento foi consagrado pelo STF no julgamento do **RE 80.004-SE**, DJ de 29.12.1977, p. 9433, RTJ 83/809, Rel. p/ acórdão Min. Cunha Peixoto (*Inf. 73/STF* — DJ de 30.05.1997), e reiterado no julgamento da **ADI 1.480-DF**, Rel. Min. Celso de Mello, no julgamento pelo Pleno do pedido de medida cautelar (j. 04.09.1997, DJ de 18.05.2001, p. 429). **Em relação à natureza dos tratados sobre direitos humanos, em razão do § 3.º do art. 5.º, trazido pela EC n. 45/2004**, confira estudo no item 9.14.5.2.3 que propugna por uma tese de **supralegalidade** ou mesmo **constitucionalidade**.
- 138 Cf.: **STF, ADI 1.480-3**, Rel. Min. Celso de Mello: medida liminar apreciada em 04.09.1997 e julgamento final do processo, sem apreciação do mérito, em 26.06.2001 (DJ de 08.08.2001), em virtude de perda superveniente do objeto do referido processo de controle abstrato de constitucionalidade (cf. *Inf. 236/STF*, 06 a 10.08.2001).
- 139 Louis Henkin, *Constitutionalism, democracy and foreign affairs*, NY: Columbia University Press, 1990, p. 59, apud Flávia Piovesan, *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*, p. 80-81.
- 140 Como bem observou Pedro Dallari, “muito embora o dispositivo mencione ‘tratados e convenções internacionais’, a doutrina, a prática e mesmo a *Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados* entendem a fórmula como redundante, já que, independentemente da denominação que tenha cada documento (tratado, convenção, acordo, pacto, carta, lei uniforme, protocolo, estatuto, concordata etc.), o vocábulo ‘tratado’ se aplica a todo acordo internacional concluído por escrito entre Estados ou organizações internacionais e que seja destinado a produzir efeitos jurídicos. Observe-se que a própria Constituição brasileira não é de forma alguma homogênea a esse respeito: o art. 49, I, faz referência a tratados e acordos; o art. 84, VIII, a tratados e convenções; o § 2.º do art. 5.º, o art. 102, III, ‘b’, o art. 105, III, ‘a’, o art. 109, III, e o § 5.º acrescido ao mesmo art. 109, apenas a tratados; e o art. 178, apenas a acordos” (Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, *Tratados internacionais na Emenda Constitucional n. 45*, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 83).
- 141 Petrônio Calmon Filho (org.), *Reforma constitucional do Poder Judiciário*, São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Processual, jan. 2000 (*Cadernos IBDP: Propostas legislativas*: 1), p. 70.

142 Flávia Piovesan entende que referidos tratados teriam caráter de norma constitucional (Reforma do Judiciário e direitos humanos, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza e Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 67). José Carlos Francisco também sustenta a constitucionalidade, até porque, quando o constituinte quis afastar a recepção automática com caráter de norma constitucional, manifestou-se expressamente, como fez com as súmulas preexistentes, nos termos do art. 8.º da EC n. 45 (Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados internacionais, in *Reforma do Judiciário*, p. 99).

143 Flávia Piovesan, *Reforma do Judiciário e direitos humanos*, p. 67.

144 Para a autora, mesmo os materialmente constitucionais (sem as formalidades das emendas), como tratam de direitos humanos, pelo art. 5.º, § 2.º, teriam natureza constitucional (Flávia Piovesan, *Reforma do Judiciário e direitos humanos*, p. 67). Mas, como visto, esse entendimento não é aceito pelo STF. Portanto, **cuidado** nas provas, especialmente as preambulares!

145 Flávia Piovesan, *Reforma do Judiciário e direitos humanos*, p. 67.

146 Araujo e Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 34.

147 Art. 4.º do Decreto-lei n. 911/69: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil”.

148 Cf. íntegra do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 466.343, em *Notícias STF*, 22.11.2006 — 20h35.

149 Cf. *Inf. n. 531/STF*, assim como **RE 349.703** e, no julgamento do **HC 87.585**, o **cancelamento da S. 619/STF** (“A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito”).

150 A questão está para ser definida no julgamento do **RE 441.280**, afetado ao Pleno (*matéria pendente*).

151 J. S. Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, 23. ed., p. 109.

152 J. S. Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, 23. ed., p. 191.

153 Nesse sentido, cf. *Inf. 408/STF*: “... No mérito, afirmou-se que, em razão de a

sociedade de economia mista constituir-se de capitais do Estado, em sua maioria, a lesão ao patrimônio da entidade atingiria, além do capital privado, o erário. Ressaltou-se, ademais, que as entidades da administração indireta não se sujeitam somente ao direito privado, já que seu regime é híbrido, mas também, e em muitos aspectos, ao direito público, tendo em vista notadamente a necessidade de prevalência da vontade do ente estatal que as criou, visando ao interesse público...”.

154 Precedentes: MS 24.268, Rel. Min. Ellen Gracie (Gilmar Mendes, p/ acórdão), *DJ* de 17.09.2004; MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, *DJ* de 25.08.2006; RE 158.543, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJ* de 06.10.1995; RE 329.001 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 23.09.2005; AI 524.143 (AgR), Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 18.03.2005.

155 O **Decreto n. 5.687/2006** promulga a *Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção*, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31.10.2003 e assinada pelo Brasil em 09.12.2003, tendo sido o seu texto aprovado pelo Congresso Nacional por meio do **Decreto Legislativo n. 348/2005**.

156 Luiz A. David Araujo e Vidal S. Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 281, estabelecem: “Já vimos que há um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que não é o mesmo do art. 128 da Constituição, mas tem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura do previsto nesse dispositivo. Sua lei orgânica não é de iniciativa do Procurador-Geral da República, mas do Tribunal de Contas da União, e não será instituída por lei complementar, mas por lei ordinária”. Esse tema será mais bem estudado quando tratarmos das **funções essenciais à Justiça** e, em especial, sobre o Ministério Público, no *item 12.2*.

157 **S. 653/STF**: “No Tribunal de Contas estadual, composto por 7 Conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar 1 dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha”.

158 Cf. ADI 2.117-MC/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, 03.05.2000 (acórdão, *DJ* de 07.11.2003). Julgamento de mérito confirmando a liminar (unanimidade) proferido em **27.08.2014**, *DJE* de 18.09.2014.

159 De acordo com o art. 77, *caput*, da *Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União* (Lei n. 8.443/92), os auditores, em número de 3, serão nomeados pelo Presidente da República, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de ministro do TCU, mediante concurso público de provas e títulos, observada a ordem de

classificação. Ainda, sobre os auditores, no mesmo diploma legal, cf.: **art. 63**: “Os Ministros, em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos, mediante convocação do Presidente do Tribunal, pelos auditores, observada a ordem de antiguidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antiguidade. **§ 1.º** Os auditores serão também convocados para substituir ministros, para efeito de *quorum*, sempre que os titulares comunicarem, ao Presidente do Tribunal ou da Câmara respectiva, a impossibilidade de comparecimento à sessão. **§ 2.º** Em caso de vacância de cargo de ministro, o Presidente do Tribunal convocará auditor para exercer as funções inerentes ao cargo vago, até novo provimento, observado o critério estabelecido no *caput* deste artigo”.

160 Cf. <<http://www.cgu.gov.br/CGU/Historico/index.asp>>.

161 Cf. *RTJ* 176/540-541; *RTJ* 176/610-611; *RTJ* 184/924; ADI 263/RO (*DJ* de 22.06.1990); ADI 1.545/SE (*DJ* de 24.10.1997); ADI 3.192/ES (*DJ* de 18.08.2006); *RTJ* 194/504-505; ADI 2.378/GO (*DJ* de 06.09.2007); ADI 1.791/PE (*DJ* de 23.02.2001); ADI 3.160 (25.10.2007, *Inf.* 485/STF).

162 Exigindo o mesmo conhecimento, cf. exames 107.º e 111.º da OAB/SP.

- 1 *Elementos de direito constitucional*, p. 156.
- 2 *Curso de direito constitucional positivo*, 35. ed., p. 109. Conforme anotou José Afonso da Silva, em outra passagem, o texto de 1988 foi inicialmente aprovado sem a cláusula que está explícita no art. 2.º, que estabelece serem os 3 “poderes” da União “independentes e harmônicos entre si”. O motivo, conforme explica, era estar sendo adotado, em um primeiro momento, o parlamentarismo, “... que é um regime mais de colaboração entre poderes que de separação independente”. A referida cláusula (de **harmonia e independência**), portanto, mostra-se muito mais adequada e conveniente no presidencialismo. “Como, no final, este é que prevaleceu, na Comissão de Redação o Prof. e então Dep. Michel Temer sugeriu a reinserção da regra da harmonia e independência que figura no art. 2.º...” (*Curso de direito constitucional positivo*, 35. ed., p. 106, nota 22).
- 3 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 27. ed., p. 542.
- 4 Lembramos que não haverá **pena de morte**, salvo em caso de **guerra** declarada, nos termos do art. 84, XIX (art. 5.º, XLVII, “a”).
- 5 No mesmo sentido: **RMS 24.079**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 05.02.2002, 1.ª T., *DJ* de 15.03.2002; **RMS 25.367**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 04.10.2005, 1.ª T., *DJ* de 21.10.2005; **RMS 24.619**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.2011, 2.ª T., *DJE* de 22.11.2011; **AI 725.590-AgR**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22.02.2011, 2.ª T., *DJE* de 15.03.2011.
- 6 Nesse sentido, pacífico o entendimento do STF dizendo não caber controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas de **legalidade**, de modo difuso. Vejamos a ementa: “Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra norma reguladora de lei que é atacada por ir além do disposto na lei regulamentada ou contra ela, porquanto nesse caso se está diante de **questão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade**. Ação de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de liminar” (ADI 1.866-DF, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 12.02.1999, p. 1, *Ement.* v. 01938-01, p. 27, j. 29.10.1998, Tribunal Pleno).
- 7 Nesse sentido, podemos citar alguns precedentes nos quais o STF reconheceu a existência de decretos autônomos passíveis de controle por meio de ADI genérica: **ADI 2.439/MS**, *DJU* de 21.03.2002; **ADI 2.155-MC/PR**; **ADI 3.673-MC**, *DJ* de 03.03.2006; **ADI-MC 309**, *DJ* de 14.02.1992; **ADI-MC 519**, *DJ* de 11.10.1991; **ADI-MC 1.590**, *DJ* de 15.08.1997; **ADI 1.396**, *DJ* de 07.08.1998; **ADI-MC 435**, *DJ* de 06.08.1999; **ADI-MC**

3.936, DJ de 09.11.2007; **ADI 3.389**, DJ de 03.03.2006; **ADI 1.308-RS**, DJ de 04.06.2004; **ADI 2.458-AL**, DJ de 16.05.2003.

- 8 O art. 77, § 1.º, estabelece que “a eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado”.
- 9 O art. 77, *caput*, com a redação atribuída pela EC n. 16/97, determinou que a eleição presidencial se faça no **primeiro e último domingos de outubro**, em **primeiro e segundo turnos** (quando houver segundo turno), do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Acontece que os parlamentares se esqueceram de alterar, também, o § 3.º do art. 77, que determina que a eleição em **segundo turno** seja feita **vinte dias** após a proclamação do resultado do primeiro turno, na hipótese de nenhum candidato ter alcançado a maioria absoluta na primeira votação. Pois bem, nesse confronto deverá prevalecer a data definida no *caput* do art. 77, na redação dada pela EC n. 16/97 (segundo turno, quando houver, no **último domingo de outubro**), mantendo-se o *quorum* definido no aludido § 3.º, na medida em que se trata de definição posterior, sem ferir qualquer dos limites colocados à manifestação do poder constituinte derivado reformador, que alterou o art. 77.
- 10 O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais (art. 79, parágrafo único). Comporá, ainda, os Conselhos da República e de Defesa Nacional (arts. 89, I, e 91, I).
- 11 Como veremos, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a CF, nos exatos termos do art. 85, *caput*.
- 12 Originalmente, o art. 82 definia o mandato presidencial em **5 anos**. Através da EC de Revisão n. 5, de 07.06.1994, o mandato passou a ser de **4 anos**, sendo, contudo, vedada a reeleição para o período subsequente. Posteriormente, a EC n. 16/97, mantendo o período do mandato em **4 anos**, inovou permitindo a reeleição para um único período subsequente não só para o Presidente da República como também para Governadores e Prefeitos, ou quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos.
- 13 Quando dizemos “exercício da Presidência” entenda-se o exercício de todos os atos inerentes à função presidencial. O substituto atua como se fosse o Presidente da República, com todas as atribuições do art. 84.
- 14 Na vigência da Constituição Federal de 1988, até o fechamento desta edição, apenas o

Ministro Marco Aurélio (5 momentos: *a)* 15.05.2002 a 21.05.2002; *b)* 04.07.2002 a 05.07.2002; *c)* 25.07.2002 a 27.07.2002; *d)* 20.08.2002 a 21.08.2002; *e)* 31.08.2002 a 09.09.2002) e o **Ministro Ricardo Lewandowski** (um único momento, de 15.09.2014 a 17.09.2014) assumiram a Presidência da República na forma do art. 80.

15 De acordo com José Afonso da Silva, “se ocorrer o fato e não houver essa lei, deve-se fazer a eleição com base em regras regimentais (ainda que por analogia), pois o texto constitucional é bastante para a prática do ato. Não se há que embarçar-se em controvérsias inúteis, quando o sistema constitucional possibilita alcançar o fim pretendido” (*Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 543, nota 5).

16 A Lei Complementar n. 97, de 09.06.1999, dispondo sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas últimas (constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica) subordinam-se ao **Ministro de Estado da Defesa** (art. 3.º c/c o art. 1.º, *caput*, da lei), que exercerá a **direção superior das Forças Armadas**, assessorado pelo *Conselho Militar de Defesa* (órgão permanente de assessoramento), pelo *Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas* e pelos *demais órgãos*, conforme definido em lei (art. 9.º, na redação dada pela LC n. 136/2010). Portanto, nesses termos, a Lei, em seu art. 20, transforma os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em Comandos, por ocasião da criação do **Ministério da Defesa**. Esse tema será mais bem estudado no *item 13.6 (Forças Armadas)*.

17 Trata-se do *referendo ministerial* dos atos (como as leis, medidas provisórias etc.) e decretos (não só os regulamentares, como também os inominados) assinados pelo Presidente da República. Michel Temer entende que se os atos e decretos presidenciais não forem referendados pelos Ministros de Estado serão **nulos** (*Elementos de direito constitucional*, p. 160). Já José Afonso da Silva sustenta que, mesmo sem o aludido referendo, os atos serão válidos e terão eficácia. Entende este último que, em caso de discordância (e, portanto, falta de referendo), o máximo que pode acontecer é a demissão do Ministro, a pedido ou não (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 561-562). Ficamos com a posição do Professor Michel Temer, na medida em que existe expressa previsão legal definida pelo poder constituinte originário.

18 Deve-se observar que as instruções são atos inferiores às **leis**, aos **decretos** e aos **regulamentos**. As instruções assumem três funções: *a)* **regulamentar as leis**, assemelhando-se, nesse caso, aos *decretos regulamentares presidenciais*, tendo o seu âmbito de validade, contudo, **restrito ao Ministério**. Observar que não existe qualquer

óbice no sentido de a referida lei ser regulamentada por decreto presidencial. Aliás, trata-se do modo normal, na medida em que hipótese de competência privativa do Presidente da República, nos exatos termos do art. 84, IV. No entanto, existindo **regulamento presidencial**, não caberá regulamentação da mesma matéria através de **instrução ministerial**. Os Ministros devem restringir-se às matérias que não tenham sido regulamentadas por decreto regulamentar presidencial (nesse caso dispõem sobre o que o decreto regulamentar deixou de disciplinar), ou toda a lei, inexistindo o regulamento presidencial; b) **regulamentar decretos**; e c) **regulamentos**.

19 Uadi Lammêgo Bulos, *Constituição federal anotada*, p. 818.

20 No mesmo sentido, **Pet. 1.656**, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 11.09.2002, Plenário, *DJ* de 1.º.08.2003. Ainda: “Em face da interpretação sistemática da Constituição, o requisito de procedibilidade a que alude seu artigo 51, I, se restringe, no tocante aos Ministros de Estado, aos crimes comuns e de responsabilidade **conexos** com os da mesma natureza imputados ao Presidente da República. Questão de ordem em que se rejeita a preliminar da necessidade, no caso, de autorização prévia da Câmara dos Deputados” (**QC 427-QO**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14.03.1990, Plenário, *DJ* 15.10.1993). Cf., também, o mesmo entendimento fixado pelo STF na vigência da Constituição pretérita (**MS 20.422**, Rezek, *DJ* de 29.06.1984).

21 Interessante notar, nos exatos termos do art. 90, § 1.º, que “o Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério”.

22 Inciso alterado pela **EC n. 23, de 02.09.1999**. A antiga redação dizia: “os Ministros militares”. Através da criação do **Ministério da Defesa**, introduzido pela aludida Emenda Constitucional, os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são transformados em **Comandos**, subordinando-se todos ao **Ministro de Estado da Defesa**.

23 Inciso acrescentado pela **EC n. 23/99**.

24 **Faixa de fronteira**, conforme estabelece o art. 20, § 2.º, da CF/88, corresponde à faixa de até **150 km** de largura, ao longo das fronteiras terrestres, sendo constitucionalmente considerada fundamental para a defesa do território nacional. A sua ocupação e utilização foram reguladas pela Lei n. 6.634/79.

25 *Phoenix* — órgão informativo do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, dez./2000, n.

26 Existem, segundo o Professor Damásio (*Direito penal*, v. 1, p. 219-221), **crimes de responsabilidade próprios** (em sentido estrito, propriamente ditos), previstos no CP (arts. 312 a 326, 150, § 2.º, 300, 301 etc.) e em legislação especial (Dec.-lei n. 201/67 e Lei n. 4.898/65); bem como os **crimes de responsabilidade impróprios** (não são crimes, mas **infrações político-administrativas**), previstos nas Leis ns. 1.079/50 e 7.106/83. Devemos salientar que concentraremos a análise sobre os **crimes de responsabilidade impróprios**, vale dizer, sobre as infrações de natureza política, ensejadoras do processo de *impeachment*. É claro que outras autoridades cometem crimes de responsabilidade. No entanto, trata-se dos de natureza própria (natureza de crime), seguindo as regras do CPP (*vide* arts. 513 e s.) ou legislação especial. *Vide item 10.4.15*, sobre sistematização das regras de competência, bem como questão sobre a responsabilização dos prefeitos.

27 Cf. **MS 23.885**, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 28.08.2002, Plenário, *DJ* de 20.09.2002. **Cuidado:** em relação a crime de responsabilidade supostamente praticado por **Ministro do STF**, a Corte tem entendido que a atribuição para esse **exame liminar**, nos termos do art. 44 da Lei n. 1.079/50, é da **Mesa do Senado Federal** (lembrando que a Câmara dos Deputados não participa do julgamento de crime de responsabilidade praticado por Ministro do STF — cf. art. 51, I (por não haver essa previsão) e art. 52, II, da CF/88), e não do Presidente da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, cf. **MS 30.672-AgR**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15.09.2011, Plenário, *DJE* de 18.10.2011, que analisava o arquivamento liminar pela Mesa do Senado Federal de pedido de instauração de processo de *impeachment* contra o Min. Gilmar Mendes formulado por determinado cidadão.

28 “Não cabe ao Senado decidir se instaura ou não o processo. Quando o texto do art. 86 diz que, admitida a acusação por dois terços da Câmara, será o Presidente submetido a julgamento perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade refoge à sua competência e já fora feito por quem cabia” (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 479).

29 Michel Temer observa: “não nos parece que, tipificada a hipótese de responsabilização, o Senado haja de, necessariamente, impor penas. Pode ocorrer que o Senado Federal considere mais conveniente a manutenção do Presidente no seu cargo. Para evitar, por exemplo, a deflagração de um conflito civil; para impedir agitação interna. Para impedir desentendimentos internos, o Senado, diante da circunstância, por exemplo, de o

Presidente achar-se em final de mandato, pode entender que não deva responsabilizá-lo” (*Elementos de direito constitucional*, p. 165).

30 Lembrar que, ao contrário do que ocorre com os crimes de responsabilidade, mesmo que haja autorização pela Câmara, o STF não é obrigado a receber a denúncia ou queixa-crime, sob pena de ferir-se o princípio da tripartição de Poderes.

31 Cf. Alexandre de Moraes, baseando-se em jurisprudência do STF (*Direito constitucional*, p. 409).

32 Exceção a essa regra se dará em relação aos parlamentares federais, por força do art. 55, VI, e § 2.º, cuja perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. (Fica claro que, por outro lado, em face do art. 15, III, não poderão disputar novas eleições enquanto durarem os efeitos da condenação — “ficha suja”. Já para a hipótese do Presidente da República, a perda do cargo será automática, em face da suspensão dos direitos políticos, por força do art. 15, III. Para aprofundamento em relação aos membros do Congresso Nacional, cf. *item 9.11.4*).

33 As regras sobre os Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica foram introduzidas pela **EC n. 23/99**, que alterou, dentre outras, a redação do inciso I do art. 52 e do art. 102, I, “c”.

34 “O Tribunal (STF, acrescente-se), por maioria, reconheceu a sua competência para conhecer e julgar queixa-crime contra o **Advogado-Geral da União**, tendo em vista a edição da Medida Provisória n. 2.049-22, de 28.8.2000, que transforma o mencionado cargo de natureza especial em cargo de Ministro de Estado, atraindo, portanto, a incidência do art. 102, I, ‘c’, da CF (‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I — processar e julgar, originariamente:... c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado,...’) (**Inq 1.660-QO**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.09.2000, Plenário, *DJ* de 06.06.2003)” (cf. *Inf. 201/STF*). Apenas alertamos, atualizando, que o *status* de Ministro de Estado do AGU, atualmente, está fixado no art. 25, parágrafo único, da **Lei n. 10.683/2003**, na redação dada pela Lei n. 12.314/2010.

35 Lembrar que a competência para processar e julgar o Procurador-Geral da República é do STF, por crime comum (art. 102, I, “b”) e do Senado Federal, por crime de responsabilidade (art. 52, II).

36 Nesse sentido, confira interessante julgado do STF que estabelece, tendo em vista o

princípio da especialidade, a prevalência da regra do art. 108, I, “a”, sobre a do art. 96, III, da CF/88, quando se estiver diante de membros do **MP da União** (art. 128, I, “a”-“d”), aplicando-se a regra do art. 96, III, **exclusivamente** aos membros do MP Estadual (competência do TJ local, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral). Cf. RE 141.209-SP (*RTJ* 140/683). RE 315.010-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, 08.04.2002, e *Inf. 263/STF, 2002*.

37 Utilizando as regras do art. 78, § 3.º, da Lei Federal n. 1.079/50, o julgamento compete a um tribunal formado por 5 membros do legislativo, 5 Desembargadores, sob a presidência do presidente do TJ local, que terá direito de voto no caso de empate. Nesse Tribunal, a escolha dos membros do Legislativo será feita mediante eleição pela Assembleia e a dos desembargadores, mediante sorteio.

38 *Direito penal*, v. 1, p. 219-221, e *Phoenix — órgão informativo do Complexo Jurídico Damásio de Jesus*, dez./2000, n. 38 — Ação penal sem crime.

39 *Direito constitucional*, 9. ed., p. 270.

40 “Somente na hipótese de **regra expressa da CF prevendo foro especial por prerrogativa de função** a agentes políticos (arts. 102, I, ‘b’ e ‘c’; 105, I, ‘a’; e 108, I, ‘a’) é que se admite a exclusão, pela Constituição de Estado-membro, da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5.º, XXXVIII, ‘d’). Com esse entendimento, a Turma negou provimento a recurso em *habeas corpus* em que se pretendia, com base em dispositivos da Constituição local, o reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça para julgar **Vereador** pela suposta prática do crime de homicídio doloso. Precedente citado: HC 78.168-PB (julgado em 18.11.98, v. *Informativo* 132. RHC 80.477-PI, Rel. Min. Néri da Silveira, 31.10.00 (RHC 80.477))” (*Inf. 208/STF*).

41 Cf. HC 74.125/PI, Min. Francisco Rezek, *DJ* de 11.04.1997, p. 12186 (j. 03.09.1996 — 2.ª Turma).

42 Cf. decisão do STJ: “Ementa: *Habeas Corpus* — Tráfico de Entorpecentes — Vereador — Foro Privilegiado — Constituição Estadual do Rio de Janeiro. 1. Não é possível o estabelecimento de foro privilegiado a vereador por legislador estadual, uma vez que a Constituição Federal não autoriza elaborar leis sobre matéria de competência processual-penal. 2. *Habeas corpus* conhecido. Pedido indeferido” (HC 11.939/RJ, *DJ* de 23.10.2000, p. 151, Rel. Min. Gilson Dipp, 5.ª Turma *Vide*, também, HC 11.749/PI; HC — 1999/0120914-5).

43 Art. 80 do CPP: “Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.

44 Apenas para efeito de informação, anotamos que o STF, em 15.08.2012, **acolheu** uma preliminar de **cerceamento de defesa** suscitada pela Defensoria Pública Federal pela falta de intimação de advogado constituído, anulando o processo a partir da defesa prévia e determinando o **desmembramento** do feito, com a remessa dos autos para a justiça de primeira instância, para dar andamento à persecução penal (*Inf. 675/STF*). O fundamento, contudo, foi diverso e não poderia ter sido diferente a decisão.

45 Questão exigindo o mesmo conhecimento nos exames 100.º, 105.º e 119.º da OAB/SP.

46 “Ação direta de inconstitucionalidade. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. **Caráter residual de decreto autônomo**. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações. Inconstitucionalidade. Ação direta. Art. 5.º da Lei 1.124/2000 do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do chefe do Executivo. **Aumento de despesas**. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos **arts. 61, § 1.º, II, ‘a’, e 84, VI, ‘a’**, da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução” (**ADI 3.232**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.08.2008, Plenário, *DJE* de 03.10.2008). No mesmo sentido: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2010, Plenário; ADI 3.983 e ADI 3.990, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.08.2008, Plenário, *Inf. 515/STF*).

- 1 Antônio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, *Teoria geral do processo*, p. 129.
- 2 Art. 5.º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Lembramos que no tocante à **jurisdição voluntária** a doutrina costuma observar que o Estado realiza a **administração pública de interesses privados**. Cintra, Grinover e Dinamarco entendem que, mesmo na jurisdição voluntária, na medida em que se busca a eliminação de situações incertas, bem como em face do procedimento verificado (através de petição, resposta, sentença, apelação...), a doutrina mais moderna vem tendendo a afirmar uma tal natureza jurisdicional (*Teoria geral do processo*, p. 156).
- 3 Existem algumas exceções a essa regra geral, como a possibilidade de concessão do *habeas corpus* de ofício pelo magistrado (art. 654, § 2.º, do CPP).
- 4 Pedro Lenza, *Teoria geral da ação civil pública*, Revista dos Tribunais, 2003, p. 295-296.
- 5 Por isso é que, como alerta Dinamarco, “... se de um lado no Estado Moderno não mais se tolera o juiz passivo e espectador, de outro sua participação ativa encontra limites ditados pelo mesmo sistema de **legalidade**. Todo empenho que se espera do juiz no curso do processo e para sua instrução precisa, pois, por um lado, ser conduzido com a consciência dos objetivos e menos apego às formas como tais ou à letra da lei; mas, por outro, com a preocupação pela integridade do *due process of law*, que representa penhor de segurança aos litigantes. É claro que, com certas atitudes menos ortodoxas ou despegadas do texto da lei, o juiz acaba por endereçar os fatos a resultados que não seriam atingidos se sua postura fosse outra e que não costumavam sê-lo antes das inovações que ele põe em prática. São atitudes marcadamente instrumentalistas, das quais significativo exemplo é a já referida *desconsideração da pessoa jurídica*...”. O juiz “... age como canal de comunicação entre a nação e o processo e... quando inovar por conta própria, *contra legem* ou fora dos limites tolerados, ele estará agindo sem fidelidade aos objetivos de sua missão e o que pretender impor carecerá de licitude ou mesmo de legitimidade” (C. R. Dinamarco, *A instrumentalidade do processo*, p. 200 — original sem grifos).
- 6 Art. 5.º, XXXVI: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, combinado com o art. 5.º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
- 7 Texto originalmente publicado em Comunidadejuridica.com: informativo eletrônico do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, São Paulo, ano II, n. 31, fev. 2005, Seção artigos.

- 8 Em relação à **defensoria pública**, remetemos o nosso ilustre leitor para o *item 12.6* no qual aprofundamos o tema, dando especial destaque para a **EC n. 80/2014**, que introduziu importantes novidades.
- 9 Logo após a aprovação da Reforma, vários sites, inclusive o do Senado Federal, divulgaram o que chamaram de Pareceres ns. 1.747 e 1.748/2004 da CCJC. O primeiro fixava a redação da EC n. 45 que seria promulgada e publicada e o segundo foi o projeto que retornou à Câmara. Alguns trabalhos utilizaram aquele texto disponível (o único à época). Acontece que, em virtude de entendimentos entre as Casas, foram procedidos ajustes nos dois pareceres, remanejando-se dispositivos daquele de n. 1.747 para o de n. 1.748, que voltou para a CD. Assim, pedimos que o ilustre colega **tome muito cuidado** com o estudo, destacando-se que, em razão da referida republicação (*DSF*, 09.12.2004, p. 41569-83), foram transferidos para a CD (na PEC n. **358/05-CD**) os seguintes dispositivos constitucionais: arts. 93, III; 102, I, “a”; 102, § 2.º; 104, parágrafo único, I; 107, *caput*; 114, I; 115, *caput*; 125, § 8.º; 103-B, VI e VIII; 111-A, II e § 1.º; e 130-A, § 2.º, IV. Para estudar somente a EC podem acessar o site www.planalto.gov.br, e cuidado para não ler o texto antigo! Para se ter acesso ao texto que está para ser votado na CD, basta acessar www.camara.gov.br e, em proposições, fazer a pesquisa selecionando “PEC” e indicando o n. 358/2005. Qualquer coisa, estamos à disposição: pedrolenza@terra.com.br.
- 10 Muito cuidado em relação ao controle de constitucionalidade, pois, conforme alertamos, o texto primeiramente publicado sobre a reforma, inclusive no site do Senado Federal, ampliava o objeto da ADC, fazendo incluir, além da lei federal, a lei estadual. Essa regra não foi aprovada e, em razão da republicação dos pareceres (*DSF* de 09.12.2004, p. 41569-83), foi transferida para a CD (na PEC n. **358/05-CD** — “PEC Paralela do Judiciário”). Assim, o único objeto de ADC continua sendo a lei federal, nos termos do art. 102, I, “a”, não alterado, apesar da modificação do art. 102, § 2.º.
- 11 *DJ* de 10.11.2006 — Ata n. 37/2006. Cf. *Inf.* 422 e 423/*STF*.
- 12 José Horácio Cintra Gonçalves Pereira, Poder Judiciário: estatuto da magistratura, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 129.
- 13 Atualmente, a LC n. 35/79 (LOMAN) vem sendo o norte dessa regulamentação, reconhecendo a sua defasagem e constantes litígios sobre a recepção de seus dispositivos, elaborados durante o regime militar. Com muito atraso, depois de quase 25 anos de

promulgação da CF/88, a **Portaria n. 47/2013-STF** instituiu a *Comissão de Estudo e Redação de Anteprojeto de Lei Complementar destinada a dispor sobre o Estatuto da Magistratura*, composta pelos Ministros Gilmar Mendes, que a presidirá, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, tendo sido designado o Juiz Leonardo de Farias Duarte para auxiliar tecnicamente, secretariando as reuniões. Até o fechamento desta edição, com **inaceitável demora** (já se vão 26 anos da promulgação da Constituição), o projeto ainda **não havia sido encaminhado**. Em **02.02.2015**, o presidente do STF, Min. Ricardo Lewandowski, em seu discurso na **cerimônia de abertura do Ano Judiciário de 2015**, prometeu o envio do referido projeto do “Novo Estatuto da Magistratura” ainda neste ano de 2015. Vamos aguardar.

14 A prática de “atividade jurídica” nos concursos, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 155.

15 *A inconstitucionalidade do critério de prática de atividade jurídica para concurso público*, São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, jun. 2004. Disponível em: <http://cjdj.damasio.com.br/?page_name=art_026_2004&category_id=32>.

16 Cf., anteriormente, MS 25.489 (*Notícias STF*, 24.08.2005).

17 MS 26.668/DF; MS 26.673/DF; MS 26.810/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 15.04.2009 (*Inf. 542/STF*): “Concurso público para cargo de técnico de provimento de apoio. Exigência de 3 anos de habilitação. Inexistência de previsão constitucional. Segurança concedida. O que importa para o cumprimento da finalidade da lei é a existência da habilitação plena no ato da posse. A exigência de habilitação para o exercício do cargo objeto do certame dar-se-á no ato da **posse** e não da inscrição do concurso”. Nesse sentido, o **Decreto n. 6.944, de 21.08.2009**, que estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, dispondo sobre normas gerais relativas a concursos públicos, em seu art. 19, parágrafo único, determina que a escolaridade mínima e a experiência profissional, quando exigidas, deverão ser comprovadas no ato de **posse** no cargo ou emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação específica.

18 Os precedentes selecionados são, até o momento, das provas para o MP, o que, sem dúvida, pode servir de orientação para as provas da Magistratura.

19 Percebam que a votação é de 17.12.2007. Em discussão mais recente, em *obter dictum* (comentário de passagem, na fundamentação), o Ministro Cezar Peluso chega a sugerir

que ser o cargo privativo de bacharel em direito não seria condição suficiente para o cumprimento do mandamento constitucional, dando como exemplo os cargos da Polícia Civil, de escrivão e de investigador, no Estado de São Paulo. O Ministro chega a sugerir a necessidade de uma análise não meramente objetiva do requisito, mas, em verdade, da essência da atividade desenvolvida. Pela leitura que fizemos, parece que o tema ainda não está firme no STF, tanto é que na ementa, em seu item 5, consta: “*Entendimento ainda não consolidado por esta Corte*”. Temos de aguardar decisões futuras, mas, de imediato, parece-nos de rigor extremamente excessivo essa suposta tendência (**MS 27.158-MC/QO**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.02.2008, *DJE* de 02.05.2008). Em **11.02.2009**, a Min. Ellen Gracie julgou **prejudicado** o pedido formulado no referido *writ* pela perda superveniente de seu objeto (art. 21, IX, do *RISTF*), ante a negativa da liminar e o prosseguimento do concurso, que foi posteriormente homologado pelo Edital n. 42/2008, publicado no *DOU* de 13.11.2008.

20 Cf. **Resolução CNJ n. 106**, de 06.04.2010, que dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2.º grau.

21 O STF decidiu pela **desnecessidade de lei complementar para dar efeitos ao art. 93, X, da CF**, em razão de sua **autoaplicabilidade**. Em caso concreto, o Plenário entendeu que a **votação de atos de remoção voluntária de magistrados** por meio de escrutínio secreto é inconstitucional: “(...). **Necessidade de motivação expressa, pública e fundamentada das decisões administrativas dos tribunais**. Regra geral, que também vincula a votação de atos de remoção de magistrados, por força da **aplicação imediata** do art. 93, X, da Constituição” (**MS 25.747**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.05.2012, Plenário, *DJE* de 18.06.2012 — original sem grifos).

22 Cf. a **Resolução CNJ n. 16, de 2 de junho de 2006**, estabelecendo critérios para a composição e eleição do Órgão Especial dos Tribunais e dando outras providências.

23 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 502. Obs.: os parênteses foram acrescentados.

24 Convém lembrar, ainda, a **independência jurídica dos juízes**, no sentido de os magistrados não se subordinarem hierarquicamente a qualquer órgão, no desempenho de suas funções. “... o juiz subordina-se somente à lei, sendo inteiramente livre na formação de seu convencimento e na observância dos ditames de sua consciência. A *hierarquia de graus de jurisdição* nada mais traduz do que uma competência de derrogação e nunca

uma competência de mando da instância superior sobre a inferior. A independência jurídica, porém, não exclui a atividade censória dos órgãos disciplinares da Magistratura sobre certos aspectos da conduta do juiz” (A. C. de A. Cintra; A. P. Grinover e C. R. Dinamarco, *Teoria geral do processo*, p. 162). Devemos destacar que a ideia de “livre convencimento” foi **abolida** pelo **CPC/2015**, que retirou a palavra “livremente” de sua redação. Isso porque o convencimento tem que ser **motivado, fundamentado**, e não “livre” (cf. art. 489 do *Novo Código*).

25 Essa matéria deverá ser aprofundada em direito administrativo, mas, desde já, adiantamos algumas regras: a **estabilidade dos servidores** nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público será adquirida após **3 anos** de efetivo exercício. Uma vez **estável**, o servidor público só perderá o cargo: *a*) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; *b*) mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa; e *c*) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Convém reforçar que, na hipótese de **insuficiência de desempenho**, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo, sendo, é claro, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 41, § 1.º, I, II e III, c/c o art. 247 da CF/88).

26 **Cuidado**, trata-se de regra nova, já que, antes da **EC n. 45/2004**, o *quorum* era de 2/3, e não maioria absoluta, e não se fixava tal competência ao CNJ, que foi criado pela *Reforma do Judiciário*.

27 Essa garantia não é exclusiva dos magistrados, na medida em que o art. 37, XV, preceitua que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4.º; 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I. Aos membros do Ministério Público, como veremos, também foi assegurada a aludida garantia (art. 128, § 5.º, I, “c”).

28 Sobre o assunto, cf. *Notícias STF*, 28.02.2007 — 18h52, e *itens 11.10 e 22.3.2.2* deste estudo. O STF, em 08.10.2008, reconheceu conexão entre a **ADI 3.854** e a **ADI 4.014** e, portanto, determinou, na forma do art. 103 do CPC/73 (correspondente ao art. 55, CPC/2015), a reunião dos feitos para tramitação e julgamento conjuntos. Em 03.06.2009, os autos voltaram da PGR com parecer favorável (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

29 O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a **95%** do subsídio mensal fixado para os Ministros do STF, e os subsídios dos demais magistrados serão

fixados em lei e **escalonados**, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a **10%** ou inferior a **5%**, nem exceder a **95%** do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4.º.

30 “Os impedimentos constitucionais dos juízes consistem em vedações que visam a dar-lhes melhores condições de imparcialidade, representando, assim, uma garantia para os litigantes” (A. C. Cintra, A. P. Grinover e C. R. Dinamarco, *Teoria geral do processo*, p. 165).

31 Cf. **Resolução CNJ n. 10/2005**, que veda o exercício, pelos integrantes do Poder Judiciário, de funções nos Tribunais de Justiça Desportiva e em suas Comissões Disciplinares (Lei n. 9.615, de 24.03.1998, arts. 52 e 53). Nesse sentido, o STF assim decidiu: “(...) A Resolução n. 10/2005, do Conselho Nacional de Justiça, consubstancia norma proibitiva, que incide, direta e imediatamente, no patrimônio dos bens juridicamente tutelados dos magistrados que desempenham funções na Justiça Desportiva e é caracterizada pela autoexecutoriedade, prescindindo da prática de qualquer outro ato administrativo para que as suas determinações operem efeitos imediatos na condição jurídico-funcional dos Impetrantes. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. As vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, **proteger o próprio Poder Judiciário**, de modo que seus integrantes sejam dotados de condições de total **independência** e, de outra parte, **garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às funções inerentes ao cargo**, proibindo que a dispersão com outras atividades deixe em menor valia e cuidado o desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado e direito fundamental do jurisdicionado. O art. 95, parágrafo único, inc. I, da Constituição da República vinculou-se a uma proibição geral de acumulação do cargo de juiz com qualquer outro, de qualquer natureza ou feição, salvo uma de magistério” (MS 25.938, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.04.2008, *DJE* de 12.09.2008).

32 Sobre o exercício de **atividades do magistério** pelos integrantes da magistratura nacional, cf. **Res. n. 34/2007** do CNJ.

33 C. R. Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, v. 1, p. 368.

34 Lembramos que os Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, são competentes para a **conciliação**, o **juízo** e a **execução** de **causas cíveis de**

menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Cf. a **Lei n. 9.099/95** sobre os juizados em âmbito estadual; a **Lei n. 10.259, de 12.07.2001**, que instituiu os **Juizados Especiais Cíveis e Criminais** no âmbito da Justiça Federal, regulamentando o art. 98, § 1.º, da CF/88 e, finalmente, a **Lei n. 12.153, de 22.12.2009**, que dispôs sobre os **Juizados Especiais da Fazenda Pública**.

35 A **Justiça de Paz**, criada pela União, Distrito Federal, Territórios (quando surgirem) e Estados, será remunerada, composta de **cidadãos** eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de **4** anos e competência para, na forma da lei, **celebrar casamentos**, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o **processo de habilitação** e exercer **atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional**, além de outras previstas na legislação. Conforme observou Bulos, “para ser juiz de paz não é necessário conhecimento jurídico, nem nível superior. Trata-se de um *juiz leigo*, não togado, podendo ser qualquer pessoa capaz, dotada de escrúpulo, maturidade e bom senso. Não gozam das garantias da magistratura (art. 95), sendo eleitos pelo voto direto, universal e secreto, dentre cidadãos domiciliados na área de atuação. O mandato é de quatro anos” (*Constituição Federal anotada*, p. 858). Sobre o assunto, cf. *item 11.11* deste estudo.

36 O **art. 108 da LOMN** (LC n. 35/79) estabelece: “poderão ser criados nos Estados, mediante proposta dos respectivos Tribunais de Justiça, Tribunais inferiores de segunda instância, denominados **Tribunais de Alçada**, observados os seguintes requisitos...”.

37 De acordo com as profundas alterações trazidas pela **EC n. 24, de 09.12.1999** (*DOU* de 10.12.1999).

38 Cabe alertar que o STF e o STJ não são órgãos da Justiça Militar Estadual. No entanto, poderão julgar, dependendo do assunto, recursos interpostos em face de acórdãos do TJ ou TJM (este quando instalado). Nesse sentido, o **STM não julgará matéria da Justiça Militar Estadual**, já que a sua competência está restrita à Justiça Militar Federal (enquanto instância recursal).

39 De acordo com o art. 2.º da Lei n. 12.153/2009, com as **ressalvas** explicitadas (sugerimos uma leitura para as provas!), é de competência dos *Juizados Especiais da Fazenda Pública* processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de **60 salários mínimos**, podendo ser partes, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

40 A íntegra do voto do Ministro relator Marco Aurélio, no julgamento do *leading case* **HC 86.834**, pode ser encontrada em *Inf. 440/STF*.

41 Cf. MS 25.982, Rel. Min. Eros Grau (*DJ* de 31.05.2006) e 24.205, Rel. Min. Ellen Gracie (*DJ* de 07.06.2002).

42 Nesse sentido já se manifestou, em voto isolado, o Ministro Marco Aurélio no MS-QO 24.674, j. 04.12.2003, *DJ* de 26.03.2004, e no MS-QO 24.691, j. 04.12.2003, *DJ* de 24.06.2005.

43 **RE 576.847**, Rel. Min. Eros Grau, j. 20.05.2009, Plenário, *DJE* de 07.08.2009, com repercussão geral. No mesmo sentido: **AI 794.005-AgR**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.10.2010, 1.^a T., *DJE* de 12.11.2010 e **RE 650.293-AgR**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.04.2012, 1.^a T., *DJE* de 22.05.2012.

44 Muito embora o art. 92, I-A, da CF estabeleça ser o *CNJ* — *Conselho Nacional de Justiça* órgão do Poder Judiciário, na medida em que **não é dotado de qualquer competência jurisdicional**, não foi considerado para a elaboração do Organograma, devendo ser entendido, então, como órgão judiciário mas não jurisdicional, ou, ainda, como **órgão administrativo**, competindo ao Conselho o controle da atuação **administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do cumprimento dos **deveres funcionais dos juízes**, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, aquelas disciplinadas no art. 103-B, § 4.º, I-VII, e que serão desenvolvidas no item 11.13.4.

45 Importante lembrar que a Constituição garante pelo menos 1/5 dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Assim, se o número total dos lugares não for múltiplo de 5, o STF posicionou-se no sentido de arredondar para cima, a fim de ter, de fato, e ao menos, 1/5 dos lugares para os juízes não oriundos da carreira.

46 “Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, deu-se a extensão, aos **tribunais do trabalho**, da regra do ‘quinto’ constante do artigo 94 da Carta Federal” (ADI 3.490, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.12.2005, *DJ* de 07.04.2006).

47 Nos termos do art. 1.º do *Provimento n. 102/2004* do Conselho Federal da OAB, a indicação de advogados para a lista sêxtupla a ser encaminhada aos Tribunais Judiciários (Constituição Federal, arts. 94; 104, parágrafo único, II; 107, I; 111-A, I; 115, I) é de competência do **Conselho Federal** e dos **Conselhos Seccionais da Ordem dos**

Advogados do Brasil (cf. art. 51 do *Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB*; arts. 54, XIII, e 58, XIV, da *Lei n. 8.906/94*).

48 Em relação ao **MP Estadual**, a lista sêxtupla (para o TJ do Estado) é elaborada pelo **Conselho Superior do MP** (art. 15, I, da *Lei n. 8.625/93*), órgão formado, nos termos do art. 14, I e II, pelo **Procurador-Geral de Justiça** e pelo **Corregedor-Geral do Ministério Público** (como membros natos) e pelos **Procuradores de Justiça** (último grau da carreira — membros elegíveis) que não estejam afastados. Por outro lado, em relação ao **MP da União** (MPF, MP do Trabalho e MP do DF e Territórios — **excluindo-se o MP Militar**, já que a escolha para o STM se dá pelo Presidente da República — art. 123 da CF/88), a lista sêxtupla será formada pelo **Colégio de Procuradores** (arts. 53, II; 94, III; e 162, III, da *LC n. 75/93*), que reúne **todos** os membros das respectivas carreiras do MPU em atividade, tornando, assim, muito mais **democrático** o processo de escolha. Por esse motivo, em **03.09.2008**, a *Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)* ajuizou a **ADI 4.134**, buscando declarar inconstitucional o procedimento de formação da lista sêxtupla no âmbito estadual, já que, com muito menor legitimidade do que o processo de escolha no âmbito do MP da União. Parece ter razão a *Conamp* (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

49 Nesse particular, o STF acolheu, por unanimidade, ratificando o entendimento firmado no julgamento da medida cautelar (08.10.2008), o pedido formulado na **ADI 4.150**, ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa”, incluída no parágrafo único do art. 63 da CE/SP pela EC n. 25/2008 (j. 25.02.2015, *DJE* de 19.03.2015). (Cf. o precedente firmado na **ADI 202**, j. 05.09.1996.)

50 Gilmar Mendes, relator, fundamentado, dentre outros argumentos, no “**pensamento jurídico do possível**”, pondera: “... cumpre observar que, ao consagrar o critério da lista sêxtupla composta por procuradores que ainda não preenchiam o requisito temporal, no caso de falta de membros habilitados, a resolução referida atendeu a um outro valor, igualmente importante para o texto constitucional: o respeito à liberdade de escolha por parte do Tribunal e do próprio Poder Executivo. Do contrário, restaria prejudicado o equilíbrio que o texto constitucional pretendeu formular para o sistema de escolha: participação da classe na formação da lista sêxtupla; participação do Tribunal na escolha da lista tríple e participação do Executivo na escolha de um dos nomes. A formação incompleta da lista sêxtupla ou até mesmo o envio de um ou dois nomes que preenchessem todos os requisitos constitucionais acabaria por afetar o modelo original

concebido pelo constituinte, reduzindo ou eliminando a participação do Tribunal e do Executivo no processo de escolha” (*Inf. 304* e transcrição no *Inf. 306/STF*. Para aprofundamento da temática da *lacuna constitucional* e do “pensamento jurídico do possível” na jurisprudência do STF, cf. *item 3.7.3*).

51 Nesse sentido, cf., ainda, Rcl 5.413, Rel. Min. Menezes Direito, j. 10.04.2008, *DJE* de 23.05.2008.

52 De acordo com o item IV do *Alvará Régio de 1808*, “a Casa da suplicação do Brasil se comporá além do *Regedor* que eu houver por bem nomear, do *Chanceler da Casa*, de 8 *Desembargadores dos Agravos*, de 1 *Corregedor de Crime da Corte e Casa*, de 1 *Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda*, de 1 *Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda*, de 1 *Corregedor do Civil da Corte*, de 1 *Juiz da Chancellaria*, de 1 *Ouvidor do Crime*, de 1 *Promotor da Justiça* e de mais 6 *Extravagantes*”.

53 A. J. Ribas, *Curso de direito civil brasileiro*, p. 121-122, apud Manoel Justino Bezerra Filho, *Súmulas do STF comentadas*, p. 34.

54 De acordo com o item I do referido Alvará, a *Casa da Suplicação do Brasil* foi “considerada como *Superior Tribunal de Justiça*, para se *findarem ali todos os pleitos em última instância*, por maior que seja o seu valor, sem que das últimas sentenças proferidas em qualquer das Mesas da sobredita Casa se possa interpor outro recurso que não seja o das revistas nos termos restritos do que se acha disposto nas minhas Ordenações, Leis e mais disposições. E terão os Ministros a mesma alçada que têm os da Casa da Suplicação de Lisboa” (BRASIL. Leis etc. *Coleção das Leis do Brasil de 1808*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891, p. 23-26).

55 José Afonso da Silva, já em 1963, propunha a criação de um “Tribunal Superior de Justiça”, correspondente ao TSE e TST, atribuindo-lhe parcela da competência que era fixada para o STF (cf. *Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro*, p. 455-456). Em 1965, o tema foi discutido na FGV por diversos juristas, tendo sido a ideia adotada na Comissão Afonso Arinos por influência do Professor Miguel Reale. A Constituição, acolhendo a proposta, preferiu batizar o novo tribunal de “Superior Tribunal de Justiça”, e não “Tribunal Superior de Justiça”, coerentemente, já que, conforme dissemos, o STJ não pertence a qualquer Justiça, sendo, ao lado do STF, órgão de superposição.

56 A título de curiosidade, meu *amigo e atento* leitor, e isso pode impressionar no exame oral (força e continue estudando!!!), o número de rejeições de nomes ao STF pelo Senado

é muito pequeno. Conforme relata Celso de Mello, em interessante e curioso texto, “**na história republicana brasileira**,

ao longo de 125 anos (1889 a 2014), o **Senado Federal**, durante o governo Floriano Peixoto (1891 a 1894), **rejeitou cinco** (5) indicações presidenciais, **negando aprovação** a atos de nomeação, para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, **das seguintes pessoas**: (1) Barata Ribeiro, (2) Innocência Galvão de Queiroz, (3) Ewerton Quadros, (4) Antônio Sève Navarro e (5) Demosthenes da Silveira Lobo”. Para se ter um comparativo, continua o ilustre Ministro, “... **nos Estados Unidos da América**, no período compreendido entre 1789 e 2014 (225 anos), o Senado norte-americano **rejeitou 12 (doze) indicações presidenciais** para a Suprema Corte americana” (cf. outras curiosidades in *Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República)*, disponível em: <www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=publicacaoPublicacaoInstitucionalCuriosidade>).

57 Cf. Uadi Lammêgo Bulos, *Constituição federal anotada*, p. 868.

58 Apenas alertamos que a alínea “a” do inciso I do art. 102 foi alterada pela EC n. 3/93. A alínea “c” do inciso I do art. 102 foi alterada pela EC n. 23/99, nos seguintes termos: “nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado **e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente”. A alínea “i” foi alterada pela EC n. 22/99: “o *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

59 “A competência do STF — cujos fundamentos repousam na Constituição da República — submete-se a **regime de direito estrito**. A competência originária do STF, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional — e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida —, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em *numerus clausus*, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o STF, por efeito da **taxatividade do rol constante da Carta Política**, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto

constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, *b* e *c*), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, *d*). Precedentes” (Pet. 1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.09.1999, *DJ* de 1.º.10.1999).

60 Cf. AI 664.567-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.06.2007, *DJ* de 06.09.2007. No mesmo sentido: AI 702.088-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.10.2008, *DJE* de 21.11.2008.

61 Cf. <<http://www.tprmercosur.org>>, acesso em 08.02.2014, bem como, neste trabalho, o *item 21.8.3*.

62 Cf. **Pet 4.383**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.10.2013, *DJE* de 10.10.2013.

63 Para se ter um contraponto, o art. 111-A, I e II, estabelece que o **TST** será composto de 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94, e os demais, qual seja, os outros 4/5, dentre juízes dos TRTs, **oriundos da magistratura da carreira**, indicados pelo próprio Tribunal Superior. No caso do **STJ**, por outro lado e conforme visto, a Constituição não fez essa exigência.

64 Interessante o conhecimento da Escola e suas atribuições, até porque, pelo mandamento da **Reforma do Judiciário**, e isso já é realidade, os cursos passam a ser **fase de ingresso** para o concurso da magistratura. Nesse sentido, cf. <www.enfam.stj.jus.br>.

65 Em relação ao assunto, remetemos o ilustre leitor para o *item 14.10.26*, no qual aprofundamos o tema.

66 Lembrar que a **EC n. 24/99** extinguiu a representação classista da Justiça do Trabalho, substituindo as **Juntas de Conciliação e Julgamento** pelos **Juízes do Trabalho**. Importante notar que a **EC n. 24, de 09.12.1999**, alterou profundamente a estrutura da Justiça do Trabalho, acabando, como já se disse, com a **representação classista**. A proposta de EC foi apresentada pelo então Senador Gilberto Miranda, em 1995, tendo sido aprovada, com o substitutivo do Senador Jefferson Péres, definitivamente, em 19.05.1999, no Senado, e em 1.º.12.1999, na Câmara. As extintas Juntas de Conciliação e Julgamento, que eram compostas de **1** juiz do trabalho, que a presidia, e **2** juízes classistas temporários

(mandato de 3 anos, de acordo com o art. 117, atualmente revogado pela EC n. 24/99), foram substituídas pelos **Juízes do Trabalho** que exercem jurisdição nas **Varas do Trabalho**, em 1.^a instância. As alterações trazidas pela EC n. 24/99 produziram inúmeras modificações na estrutura da Justiça do Trabalho, principalmente em relação à composição dos tribunais.

67 Cf. os seguintes precedentes: CComp 7.204, Rel. Min. Carlos Britto, *DJ* de 09.12.2005; AI 529.763 (AgR-ED), Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 02.12.2005; AI 540.190 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 25.11.2005; AC 822 (MC), Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 20.09.2005. Cf., ainda, *Inf.* 394/STF (CC 7.204 — Rel. Min. Carlos Britto, 29.06.2005).

68 RE 504.374-AgR, Rel. Min. Carlos Britto; AI 656.107-AgR, Rel. Min. Eros Grau; CC 7.456, Rel. Min. Menezes Direito, j. 07.04.2008, *DJE* de 20.06.2008; AI 663.722-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.09.2008, *DJE* de 17.10.2008; RE 461.925-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; CC 7.430; CC 7.441; CC 7.221; CC 7.505, j. 26.12.2008, CC 7.644, j. 13.05.2009 etc.

69 Cf., ainda, no mesmo sentido, julgamento da 4.^a Turma do **TST** — *RR-1001-2006-751-04-00.3*, j. 10.12.2008. O tema é novo e merece um acompanhamento da jurisprudência, especialmente do STF, apesar da decisão proferida no **RE 607.520**, conforme mencionado.

70 “EMENTA: **Justiça do Trabalho**: Competência: Const., art. 114: ação de empregado contra o empregador, visando a observância das condições negociais da promessa de contratar formulada pela empresa em decorrência da relação de trabalho. 1. Compete à **Justiça do Trabalho** julgar demanda de servidores do Banco do Brasil para compelir a empresa ao cumprimento da promessa de vender-lhes, em dadas condições de preço e modo de pagamento, apartamentos que, assentindo em transferir-se para Brasília, aqui viessem a ocupar, por mais de 5 anos, permanecendo a seu serviço exclusivo e direto. 2. A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil, mas sim, no caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo e o fundamento do pedido, tenha sido feita em razão da relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho” (CJ 6.959, Rel. Min. Célio Borja, j. 23.05.1990, Plenário, *DJ* de 22.02.1991).

71 Convém lembrar que, em tempo de guerra ou durante o estado de sítio, a jurisdição superior militar será exercida, de acordo com as regras dos arts. 89 e s. da Lei de

Organização Judiciária Militar, Lei n. 8.457/92, pelos **Conselhos Superiores de Justiça Militar**.

72 O quadro foi construído com base na Lei n. 6.880/80 (*Estatuto dos Militares*) e nos sites das respectivas Forças Armadas: a) **Marinha** (<http://www.mar.mil.br>); b) **Exército** (<http://www.exercito.gov.br>); c) **Aeronáutica** (<http://www.fab.mil.br>), no ícone “postos e graduações”. Naturalmente, aguardamos qualquer crítica ou sugestão para o nosso e-mail pessoal (pedrolenza@terra.com.br).

73 De acordo com o art. 16, § 4.º, da Lei n. 6.880/80, os **alunos** de órgãos específicos de formação de militares são denominados **praças especiais**. Por sua vez, o art. 19 da referida lei regula a precedência entre as praças especiais e as demais praças. Dessa forma, no quadro, atentar que existem **alunos** alocados como *graduados*. Contudo, pela disposição legal, devem ser considerados **praças especiais** (já que **alunos**, conforme visto). Essa situação não tem como ser evitada, para efeitos do *quadro didático*, já que priorizamos a indicação do **grau hierárquico** das autoridades.

74 Os alunos de Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre os Terceiros-sargentos, aos quais são equiparados (isso vale para as três Forças Armadas).

75 Os alunos dos órgãos de formação de Oficiais da reserva, **quando fardados**, têm precedência sobre os Cabos, aos quais são equiparados, valendo essa regra para todas as Forças Armadas.

76 Por esse motivo, o candidato atento tem conhecimento de que, dentre as matérias que constam nos **Editais** para ingresso no **cargo de Defensor Público Federal** da Carreira de *Defensor Público da União*, estão **direito penal militar** e **direito processual penal militar**.

77 “A competência da Justiça Militar Estadual é definida em razão da matéria (crime militar) e da pessoa (policia militar). O policia militar da reserva ou reformado equipara-se ao policia em atividade para fins de aplicação da lei penal militar. A exclusão, demissão ou exoneração do serviço militar não retira a competência da Justiça Militar, desde que o fato tenha sido praticado ao tempo em que o agente era policia militar (art. 5.º do Código Penal Militar). A lei penal militar poderá, nesse caso, alcançar ex-policiais militares” (cf.: <www.tjmsp.jus.br> — institucional — competência).

78 Em se tratando de **crime culposo** praticado por civil contra militar, como inexistente o

intuito de atingir a administração militar, o STF entendeu ser competente a Justiça comum para o julgamento. Cf. CComp 7.040-RS (*DJU* de 22.11.1996); HC 81.161-PE (*DJU* de 14.12.2001); HC 81.963-RS, Rel. Min. Celso de Mello, 18.06.2002; HC 81.963 e *Inf. 273/STF*. Nesse sentido, cf. **HC 105.348/RS**, Rel. Min. Ayres Britto, 19.10.2010, *Inf. 605/STF*.

79 Reforma do Poder Judiciário e Justiça Militar, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 383.

80 Reforma do Poder Judiciário e Justiça Militar, cit., p. 383.

81 A reforma na Justiça Militar estadual, em face da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 409.

82 Na Justiça Militar da União, a nomenclatura ainda continua juiz-auditor, embora, na Justiça Militar Estadual, a EC n. 45/2004 tenha denominado os juízes-auditores **juízes de direito do juízo militar** — art. 125, § 5.º).

83 Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Reforma do Poder Judiciário e Justiça Militar, cit., p. 383.

84 “EMENTA: **Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4.º, parte final, da Constituição**, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: **caducidade do art. 102 do Código Penal Militar**. O artigo 125, § 4.º, *in fine*, da Constituição, de **eficácia plena e imediata**, subordina a perda de graduação dos praças das polícias militares à **decisão do Tribunal competente**, mediante **procedimento específico**, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A **EC 18/98**, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), **não revogou o art. 125, § 4.º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças**” (**RE 358.961**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10.02.2004, Pleno, *DJ* de 12.03.2004). Nesse mesmo sentido, cf. **RE 121.533**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 26.04.1990, Pleno, *DJ* de 30.11.1990. **CUIDADO**: entendimento superado no **RE 447.859** (j. 21.05.2015).

85 Conforme alertamos, esse novo entendimento, firmado pelo STF no julgamento do **RE 447.859**, se deu por votação bastante apertada (6 x 5). O Min. Fux não votou, nem mesmo o Min. Fachin. Assim, temos que acompanhar eventual alteração futura do

entendimento que, em nosso entender, seria uma **melhor** interpretação (pendente de manifestação de novos Ministros).

86 Alertamos que pode haver alguma particularidade em cada Estado, por exemplo, a existência de *Soldado de 1.ª Classe* e de *2.ª Classe*, pedindo, assim, que o nosso ilustre leitor confira de acordo com a necessidade de preparação para eventual concurso específico. Boa sorte!

87 O *Aluno Oficial* (em algumas escolas militares chamado de *Cadete*), quando se forma, é promovido, por mérito intelectual, a *Aspirante a Oficial*. Ao final do estágio probatório, o *Aspirante a*

Oficial é promovido, por merecimento intelectual, a *2.º Tenente*. Para se ter um exemplo, podemos citar, no Estado de São Paulo, o concorrido concurso público de provas e títulos (atualmente VUNESP) para o *Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública — BCPSOP*, na *Academia de Polícia Militar do Barro Branco — APMBB*, estabelecimento de ensino superior, de regime especial, da PMSP, com duração de 4 anos.

88 Até o advento da EC n. 24/99 as Juntas de Conciliação e Julgamento também podiam ser citadas nesse rol. Atualmente, contudo, tendo sido extinta a representação classista, a jurisdição trabalhista, em primeira instância, é exercida por um juízo monocrático, qual seja, pelo Juiz do Trabalho.

89 Nesse sentido, em relação à Justiça Estadual, destacamos: “EMENTA: Conflito de competência. Invasão de terras. Fato não atentatório à ordem política e social. Competência da **Justiça Estadual**. Constituição art. 126. **Inocorrendo atentado à ordem política e social**, mas apenas **conflito fundiário**, embora grave, declara-se a competência da Justiça Estadual” (STJ, 3.ª S., CComp 1.111/RS, Rel. Min. José Cândido de Carvalho Filho, *DJ* de 04.06.1990, p. 5052).

90 Eneas de Oliveira Matos, Varas Agrárias na Emenda Constitucional 45/2004, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 425.

91 Cf., nesse sentido: “O inciso IV do art. 109 da Constituição, ao atribuir competência à Justiça Federal para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de interesse da União, não tem a extensão pretendida pelos impetrantes, até porque no cenário desta singular amplitude seria muito difícil excluir alguma infração penal que não fosse praticada em detrimento dos interesses diretos ou indiretos da União. O inciso XI do

mesmo artigo confere competência à Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, os quais são aqueles indicados no art. 231 da Constituição, abrangendo os elementos da cultura e os direitos sobre terras, não alcançando delitos isolados praticados sem qualquer envolvimento com a comunidade indígena” (HC 75.404, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 27.06.1997, *DJ* de 27.04.2001). No mesmo sentido: RHC 85.737, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12.12.2006, *Inf. 452/STF*. No julgamento do HC 91.121 (06.11.2007), o STF entendeu serem da competência da Justiça Federal “somente os processos que versarem sobre questões diretamente ligadas à **cultura indígena**, aos **direitos sobre suas terras**, ou, ainda, a **interesses constitucionalmente atribuíveis à União Federal** competiriam à Justiça Federal. Neste ponto, ordem indeferida por vislumbrar hipótese de incidência da jurisdição da Justiça Federal em face ‘da relação com a disputa de terras reivindicadas pela FUNAI e pela União como indígenas’”.

92 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 22. ed., p. 632.

93 *Constituição de 1824*: “Art. 161. Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum”.

94 *Constituição de 1824*: “Art. 162. Para este fim haverá juizes de paz, os quais serão eletivos pelo mesmo tempo e maneira por que se elegem os vereadores das câmaras. Suas atribuições e distritos serão regulados por lei”.

95 *Constituição de 1934*: “Art. 104, § 4.º Os Estados poderão manter a Justiça de Paz eletiva, fixando-lhe a competência, com ressalva de recurso das suas decisões para a Justiça comum”.

96 *Constituição de 1946*: “Art. 124, X — poderá ser instituída a Justiça de Paz temporária, com atribuição judiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou recorríveis, e competência para a habilitação e celebração de casamentos e outros atos previstos em lei”.

97 *Constituição de 1967*: “Art. 136, § 1.º A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça: ... c) Justiça de Paz temporária, competente para habilitação e celebração de casamentos e outros atos previstos em lei e com atribuição judiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou irrecorríveis”.

98 *EC n. 1/69*: “Art. 144, § 1.º A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça: ... c) Justiça de Paz temporária, competente para habilitação e celebração de casamento”.

99 Para se ter um exemplo, o anteprojeto de lei que *dispõe sobre o provimento de*

mandato eletivo de juiz de paz, no âmbito do DF e Territórios, em seu art. 17, estabelece que “o juiz de paz perceberá **subsídio mensal**, fixado em **parcela única** de **R\$ 6.192,03** (seis mil, cento e noventa e dois reais e três centavos), nos termos do art. 39, § 4.º, da Constituição Federal”. De maneira **muito mais tímida**, a *Lei mineira n. 13.454/2000* fixa a remuneração mensal em subsídio nos valores de **R\$ 263,00 a R\$ 800,00**, de acordo com a lotação do juiz de paz: a) município-sede de comarca (variando da entrância inicial para a final); b) município que não seja sede de comarca; c) distrito judiciário.

100 O Presidente do **CNJ**, no uso de suas atribuições, editou a **Recomendação n. 16/2008** (*DJE* de 04.09.2008) recomendando aos **Tribunais de Justiça dos Estados** e do **Distrito Federal e Territórios** que, em observância ao art. 98, II, da CF/88, **no prazo de 1 ano a partir da publicação**, regulamentem a função de juiz de paz, encaminhando proposta de lei à Assembleia Legislativa (e, no caso do DF, ao CN, acrescente-se) que trate: “**1.** Das eleições para a função de juiz de paz, na capital e no interior; **2.** Da remuneração para a função de juiz de paz, na capital e no interior; **3.** Da atuação dos juízes de paz perante as Varas de Família; **4.** Da atuação dos juízes de paz na atividade conciliatória”. Até o fechamento desta edição, não se tem conhecimento de novas leis estaduais, além da de Minas Gerais.

101 Cf. *Inf. 391/STF e Notícias STF*, 16.06.2005 — 20h11. Para leitura do acórdão, cf. **ADI 2.938**, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.06.2005, Plenário, *DJ* de 09.12.2005.

102 ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011, Plenário, *DJE* de 26.05.2011.

103 Nesse sentido, o Min. Ayres Britto faz importante distinção entre os **notários** e os **juízes de paz**. Os notários são remunerados por emolumentos porque são delegatários de atividade pública **exercida em caráter privado** (cf. art. 236, da CF/88). Por sua vez, os juízes de paz são **agentes públicos** e, assim, integrando a magistratura, estão proibidos de receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processos (voto na ADI 954).

104 *Curso de direito processual civil*, 16. ed., v. 2, p. 261.

105 **S. 655/STF**: “A exceção prevista no art. 100, ‘caput’, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, **não dispensa a expedição de precatório**, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza”.

106 Lei n. 9.469/97: “Art. 6.º Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal, estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem cronológica da apresentação dos precatórios judiciais e à conta do respectivo crédito. § 1.º É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de **natureza alimentícia**, obedecida, entre eles, a ordem cronológica de apresentação dos respectivos **precatórios judiciais**”.

107 Conforme decidiu o STF, “não viola o art. 100, § 4.º (agora § 8.º, com a EC n. 62/2009), da CF (...) o fracionamento do valor da execução em parcelas **controversa** e **incontroversa** sem que isso implique alteração do **regime de pagamento**, que é **definido pelo valor integral da obrigação**. Com base nesse entendimento, a Turma manteve acórdão do TRF da 4.ª Região que determinara, em face da ausência de impugnação nos embargos, o prosseguimento de execução contra a Fazenda Pública na parte incontroversa. (...) Asseverou-se que a vedação prevista no § 4.º (§ 8.º, acrescenta-se) do art. 100, da CF não teria ocorrido no caso e que a obrigatoriedade de sentença transitada em julgado (CF, art. 100, § 1.º — § 5.º com a EC n. 62/2009) fora observada, uma vez que da parte incontroversa não cuidará a sentença dos embargos à execução”, sendo, assim, possível a **expedição de dois precatórios**, um relativo à parte incontroversa e outro, posterior, quando for definido o valor referente à parte controversa (*Inf. 430/STF*, RE 484.770/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 06.06.2006).

108 Para se ter um exemplo, o art. 1.º da **Lei n. 10.099, de 19.12.2000**, dando nova redação ao art. 128 da Lei n. 8.213/91, regulamentando o disposto no **art. 100, § 3.º, da CF**, definiu **obrigações de pequeno valor, para a Previdência Social**, aquelas demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados na referida Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, cujos valores de execução não forem superiores a **R\$ 5.180,25** por autor, podendo, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até **60 dias**, após a intimação do trânsito em julgado da decisão, **sem necessidade da expedição de precatório**. Outro exemplo foi trazido pela **Lei n. 10.259, de 12.07.2001**, que instituiu os **Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal**. De acordo com a nova lei, compete ao Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de **60 salários mínimos**, considerado “**pequeno valor**”, para efeitos do § 3.º do art. 100 da CF/88, devendo ser pago independentemente de expedição de precatório, mediante mera **requisição judicial** (arts. 3.º, *caput*, e 17, da Lei n. 10.259/2001). No

âmbito dos **Juizados Especiais da Fazenda Pública**, que têm por competência processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos, até que se dê a publicação das leis definindo o conceito de *obrigação de pagar quantia certa de pequeno valor*, consideram-se, como tal, **40 salários mínimos**, quanto aos **Estados** e ao **Distrito Federal** e **30 salários mínimos**, quanto aos **Municípios** (art. 13, § 3.º, da Lei n. 12.153, de 22.12.2009).

109 ADI 4.357 e ADI 4.425, Rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. 13 e 14.03.2013, Plenário, *DJE* de 26.09.2014.

110 O STF declarou **constitucional** essa sistemática da “**superpreferência**”: “o **pagamento prioritário**, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave **promove**, com razoabilidade, a **dignidade da pessoa humana** (CF, art. 1.º, III) e a **proporcionalidade** (CF, art. 5.º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela EC n. 62/2009” (ADI 4.357 e ADI 4.425).

111 “EMENTA: 5. A **atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade** (CF, art. 5.º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (*ex ante*), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é **inidôneo** a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da **isonomia** (CF, art. 5.º, *caput*) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (*ex vi* do art. 161, § 1.º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade (...) para **determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário**”.

112 Conforme vimos no *item 11.12.6*, após ter declarado a inconstitucionalidade dessa forma de atualização monetária, o STF modulou os efeitos da decisão proferida nas ADIs

4.357 e 4.425 (efeito *ex nunc*) e manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/2009, até **25.03.2015**, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Ainda, como desdobramento desse efeito prospectivo, a Corte resguardou os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/2013 e n. 13.080/2015, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.

113 Art. 97, § 3.º, do ADCT: “Entende-se como **receita corrente líquida**, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1.º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas: I — nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; II — nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9.º do art. 201 da Constituição Federal”.

114 “EMENTA: (...). O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC n. 62/2009, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1.º, *caput*), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2.º), o postulado da isonomia (CF, art. 5.º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5.º, XXXV), o direito adquirido e a coisa julgada (CF, art. 5.º, XXXVI)”.

115 José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, 22. ed., p. 485-486.

116 José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, 22. ed., p. 1057.

117 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *Direito administrativo*, 22. ed., p. 461-462.

118 Ricardo Cunha Chimentí, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 139.

119 Cabe observar que a *Emenda Regimental n. 1, de 09.03.2010*, alterou o RI/CNJ para se adequar à regra introduzida pela EC n. 61/2009. Assim, de acordo com a nova redação dada ao Regimento Interno: “Art. 23. Os Conselheiros serão substituídos em suas

eventuais ausências e impedimentos: I — o **Presidente do Conselho** (que é o Min. Presidente do STF, acrescente-se), pelo **Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal**” (nos exatos termos da regra prevista no art. 103-B, § 1.º, da CF/88). Porém, o art. 23, § 1.º, do *RI/CNJ* estabelece que, no caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho **e do seu substituto, o Vice-Presidente do STF**, substituirá o Presidente o **Conselheiro** por ele **indicado**. Com o máximo respeito, entendemos que essa regra de substituição em caso de impedimento do substituto do Presidente, que é o Vice-Presidente do STF (e, conforme visto, nem sequer faz parte da composição do CNJ), **viola** a Constituição. A intenção da reforma, buscando manter o caráter institucional da direção, a nosso ver, foi deixar a **presidência do CNJ** “nas mãos” de **Ministro do STF**, mesmo no caso de substituição, o que não se verificará na hipótese indicada na nova redação dada ao art. 23, § 1.º, do *RI/CNJ*.

120 Nesse sentido, decidiu a Corte: “A **competência exclusiva, indelegável e absoluta** para **presidir** a sessão do CNJ fixou-se, a partir do advento da EC 61/2009, na pessoa do **presidente** ou, na sua ausência, do vice-presidente do STF, nos termos do disposto no art. 103-B, § 1.º, da Constituição de 1988. Ressalva do redator do acórdão que reconheceu a impossibilidade de, mesmo antes do advento da EC 61, uma sessão do CNJ ser presidida por conselheiro não oriundo do STF, decidindo, quanto ao ponto, pela necessidade de modulação temporal...” (**MS 28.003**, Rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. 08.02.2012, Plenário, *DJE* de 31.05.2012). Essa regra, em nosso entender inquestionável, gerou problemas durante o julgamento da **AP 470** (“mensalão”) que, de modo muito particular, praticamente, ocupou toda a pauta do Plenário do STF durante o 2.º semestre de 2012. Cogitaram-se alternativas para que o CNJ não ficasse paralisado, já que o STF apreciava, inclusive em pautas extraordinárias, a referida ação penal, com o seu Presidente nas sessões. Tratava-se do julgamento mais complexo de toda a história do STF, em 53 sessões de julgamento, com 38 réus, 234 volumes, 495 apensos e um total de 50.199 páginas! Mesmo assim, para nós, a regra da Constituição não poderia ser alterada. A presidência do CNJ é exclusiva do Presidente do STF e, na sua ausência, poderá ser exercida, por autorização constitucional, pelo Vice-Presidente do STF.

121 Conforme acentuado pelo **IBDP** em sede de conclusões, em primoroso trabalho de acompanhamento da **Reforma do Judiciário**, a **oposição**, na Câmara dos Deputados, considera **inaceitável a composição do Conselho Nacional da Magistratura** da maneira como apresentada na PEC, reivindicando a sua **formação** preponderantemente por **pessoas alheias à Magistratura**, a fim de dar-lhe verdadeira feição de **controle**

- externo**, uma das razões, segundo o relatório do IBDP, que impediu a sua apreciação definitiva no ano de 1999. No entanto, como já exposto, o modelo vindicado pela oposição seria, fatalmente, declarado inconstitucional pelo STF, só se podendo falar em verdadeiro controle externo através da manifestação do poder constituinte originário, elaborando uma nova Constituição, este sim, ilimitado juridicamente, soberano na tomada de suas decisões, incondicionado. (Cf. conclusões do IBDP, in *Reforma constitucional do Poder Judiciário* (org. Petrônio Calmon Filho), São Paulo: IBDP, v. 1, p. 169.)
- 122 A Reforma do Judiciário, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 193.
- 123 **ADI 3.367**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.04.2005, *DJ* de 22.09.2006.
- 124 **MS 25.888**, bem como **RE 441.280**, afetado ao Pleno (*matéria pendente*).
- 125 **MS 32.582-MC**, decisão monocrática proferida em 03.02.2014, deferindo pedido de liminar formulado pelo Estado do Amazonas. Em seu relatório, resumiu o Min. Celso de Mello: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato emanado de eminente Conselheiro Relator do E. Conselho Nacional de Justiça, ratificado pelo Plenário daquele órgão, que determinou ao eminente Senhor Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que se abstenha de adotar providências necessárias à execução da Lei Complementar amazonense n. 126/2013, **por aparente vício de inconstitucionalidade de referido diploma legislativo**, além de haver neutralizado os efeitos decorrentes do envio de outro projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos administrativos no âmbito do ‘2.º grau de jurisdição’” (*mérito pendente*). No mesmo sentido, cf.: **MS 32.865-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 02.06.2014, *DJE* de 05.06.2014.
- 126 A **ADI 4.638** trata de vários assuntos contidos na citada Res. n. 135/CNJ. Destacamos apenas a questão concreta do art. 12. Sugerimos a leitura de referida resolução e as informações sobre o resultado do julgamento em *Infs. 653 e 654/STF* e *Notícias STF* de 08.02.2012 (o acórdão com 487 fls. foi publicado no *DJE* de 30.10.2014).
- 127 René David, *Os grandes sistemas do direito contemporâneo*, p. 17.
- 128 André Ramos Tavares, *Nova lei da súmula vinculante: estudos e comentários à Lei 11.417 de 19.12.2006*, p. 20.
- 129 André Ramos Tavares, *Nova lei da súmula vinculante*, p. 21.
- 130 Walber de Moura Agra, *A reconstrução da legitimidade do Supremo Tribunal*

Federal: densificação da jurisdição constitucional brasileira, p. 122-123.

131 Roger Stiefelmann Leal, comparando o efeito vinculante e o *stare decisis*, observa que “... o efeito vinculante impõe liame de caráter obrigatório, paranormativo, aos órgãos e poderes que se aplica. No caso do *stare decisis*, embora se fale em vinculação dos precedentes (*binding precedents*), aos juízes inferiores se reconhecem mecanismos para sua insubordinada superação (*overruling*). Assim, cabe aos demais órgãos do Poder Judiciário, mediante técnicas decisórias específicas — tais como a superação antecipada (*anticipatory overruling*) ou superação implícita — desgarrarem-se dos precedentes da Suprema Corte e decidirem casos de maneira diversa” (p. 117). Nessa mesma linha de superação do precedente pelo *trial judge*, citando Charles D. Cole, cf. M. A. B. Muscari, *Súmula vinculante: um estudo à luz da Emenda Constitucional 45*, p. 84. Nessa linha, segundo Silvio Nazareno Costa, o precedente pode ser afastado pelo juiz na hipótese em que a sua aplicação acarrete “clara injustiça”, ou implique “incompatibilidade legal absoluta (na hipótese de precedente baseado em lei revogada ou modificada)”, ou “constitua irracionalidade evidente” (*Súmula vinculante*, p. 10).

132 A. Sormani; N. L. Santander, *Súmula vinculante*, p. 41.

133 Gilmar Ferreira Mendes, *Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha*, p. 277-287. Sobre a influência da Constituição de Weimar no surgimento do controle abstrato, cf. Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes (coord.), *Ação declaratória de constitucionalidade*, p. 59 e s. Sobre o efeito vinculante no modelo germânico, cf. *Ação declaratória...*, cit., p. 100-101. Destacamos, ainda, a tendência alemã a atribuir o efeito vinculante não só ao dispositivo da sentença como, também, aos **fundamentos determinantes** (*tragende Gründe*) (*Ação declaratória...*, cit., p. 100).

134 Nesse sentido, cf. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 1009-1012.

135 C. L. A. Rocha, Sobre a súmula vinculante, p. 53. Cf., ainda, Jorge Miranda, *Manual de direito constitucional*, t. 6, p. 252-276.

136 “Art. 19. O Tribunal Supremo de Justiça enviará todos os anos ao Governo uma relação das causas, que foram revistas, indicando os pontos sobre que a experiência tiver mostrado vício, ineficiência da legislação, as suas lacunas e incoerências, **para o Governo propor ao Corpo Legislativo, a fim de se tomar a resolução que for conveniente**”.

137 V. N. Leal, Atualidades do Supremo Tribunal, *RF* 208/17.

138 V. N. Leal, *Atualidades do Supremo Tribunal*, RF 208/16.

139 Cf. **ADI 3.695**, ajuizada, em 29.03.2006, pelo Conselho Federal da OAB, contra a íntegra da Lei federal n. 11.277/2006 (que incluiu o art. 285-A e parágrafos no CPC/73), sob o argumento de que a nova regra “institui uma sentença vinculante, impeditiva do curso do processo em primeiro grau”. Há pedido de ingresso do *IBDP* — *Instituto Brasileiro de Direito Processual* como *amicus curiae*, defendendo a constitucionalidade da lei.

140 Cf. **ADI 3.740**, ajuizada, em 30.05.2006, pelo Conselho Federal da OAB, contra o § 1.º do art. 475-L e o parágrafo único do art. 741 do CPC/73, com a redação alterada pela Lei n. 11.232/2005; bem como o parágrafo único do art. 741 do CPC/73, na redação conferida pela MP n. 2.180-35. Alega a OAB violação ao princípio da segurança jurídica e autoridade do Poder Judiciário.

141 Segundo o *Relatório n. 1/2006 da Comissão Mista Especial para a Reforma do Judiciário*, “esse tratamento diferenciado se dá porque há o risco de inviabilização dos trabalhos do STF se for aberta a possibilidade de propositura de medidas autônomas por municípios (mais de 5.000, atualmente) (...). Neste caso, a autorização legal para que requeiram incidentalmente a edição de súmulas vinculantes, cria um filtro, e não os alija totalmente do processo”. Apenas a título de curiosidade, lembramos que, segundo o *Censo 2010* (IBGE), o Brasil tem **5.564** municípios (não estamos considerando Brasília, apesar de o Censo a listar, pois, conforme já afirmamos, Brasília não se enquadra no conceito de cidades por não ser sede de município. Brasília, na forma do art. 18, § 1.º, da CF/88, é a Capital Federal. Ainda a título de curiosidade, o Estado com o menor número de municípios é Roraima (15) e o com o maior número é Minas Gerais (853) (Fonte: IBGE, disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat>>).

142 Conforme apontamos no *item 11.14.12*, a partir da publicação da Lei n. 12.433/2011, entendemos indispensável a revisão ou o cancelamento da referida *SV 9/STF* (**matéria pendente**).

143 Dentre outros precedentes, cf. **Rcl 6.541** e **Rcl 6.856**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 25.06.2009, Plenário, *DJE* de 04.09.2009.

144 Sobre a **natureza jurídica** do instituto da reclamação, cf. *item 6.7.1.18.2*.

145 *Notícias STF*, 08.02.2007.

146 Aprovado na 68.ª Sessão Ordinária do CNJ, do dia 06.08.2008, nos autos do Processo

n. 200820000007337.

147 Apenas para conhecimento da matéria, estabeleceu o STF: “Competência — Justiça Militar *versus* Justiça Federal *stricto sensu* — Crime de falso — Carteira de habilitação naval de natureza civil. A competência para julgar processo penal a envolver a falsificação de carteira de habilitação naval de natureza civil é da **Justiça Federal**, sendo titular da ação o MPF” (**HC 90.451**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.08.2008, *DJE* de 03.10.2008). No mesmo sentido: HC 109.544-MC, HC 106.171, HC 104.619, HC 104.804, HC 104.617, HC 103.318, HC 96.561, HC 96.083, HC 110.237 etc.

148 Cf. MS 13.040/DF, 3.^a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJE* de 1.^o.09.2008, e RE nos EDcl no MS 9.516, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 26.11.2008 e *DJE* de 09.12.2008.

149 **Art. 127 da LEP (Lei n. 7.210/84)**: “Em caso de **falta grave**, o juiz poderá revogar **até 1/3 (um terço)** do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar” (*Redação dada pela Lei n. 12.433/2011*). Assim, ao que parece, o STF tende a manter o entendimento exposto na SV 9, no sentido da possibilidade de o juiz revogar o tempo remido em caso de falta grave, mas, agora, diante da nova regra, **até o limite máximo de 1/3**, ensejando, portanto, a necessidade de sua **revisão** ou **cancelamento**. Até o fechamento desta edição, referida súmula ainda estava em vigor, apesar de haver sinalização de sua revisão, conforme consistente manifestação do Min. Fux no julgamento do **RE 638.239**, com parecer do MPF no sentido de o juízo da Execução examinar a perda dos dias remidos **de acordo com a alteração introduzida pela Lei n. 12.433/2011** (manifestação da PGR de 29.11.2011) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**). Em outro julgado, o STF determinou a aplicação da nova lei, até porque mais benéfica (cf. **HC 110.040/RS**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.11.2011). Assim, o meu ilustre leitor, ao estudar o assunto, especialmente para as provas de *direito penal* e *direito processual penal*, deverá conferir se a SV 9/STF ainda está em vigor, apesar da sua incontestável **superação** a partir do advento da Lei n. 12.433/2011, que, por introduzir, de modo mais **benéfico**, regra de direito material, tem **aplicação retroativa**, atingindo, portanto, as execuções penais em andamento referentes a fatos praticados e anteriores à vigência do referido ato normativo. Cabe, finalmente, lembrar que, nos termos do art. 5.^o da Lei n. 11.417/2006 (*que regulamentou o art. 103-A da CF/88, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF*), revogada ou **modificada** a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou

por provocação, **procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso.**

150 A **SV n. 37**, junto com as de ns. 34 a 36, foi aprovada em **16.10.2014**. Referida súmula vinculante (37) é fruto de conversão da **Súmula n. 339/STF** (editada em 13.12.1963). Nesse sentido, outros **21 verbetes** de **súmulas da jurisprudência predominante** (que não são vinculantes — numeradas de 1 a 736, sendo essa última aprovada na Sessão Plenária de 26.11.2003) estão sendo ou já foram analisados pela Corte (cf. propostas de súmulas vinculantes — PSVs ns. 88 a 109, em razão do acolhimento do parecer do PGR no sentido de desdobramento da PSV n. 70 — Min. Gilmar Mendes, encaminhada em 2012). Conforme indicamos em seguida, alguns já foram, inclusive, convertidos em súmulas vinculantes. De acordo com o *Ofício n. 005/MGM*, encaminhado pelo Min. Gilmar Mendes em 22.03.2012, “os verbetes indicados — a saber: os de número **339** (*SV* 37), **645** (*SV* 38), **646** (*SV* 49), **647** (*SV* 39), **650**, **651**, **661** (*SV* 48), **666** (*SV* 40), **669** (*SV* 50), **668**, **670** (*SV* 41), **672** (*SV* 51), **680**, **681** (*SV* 42), **685** (*SV* 43), **686** (*SV* 44), **688**, **721** (*SV* 45), **722** (*SV* 46), **724** (*SV* 52), **725** e **730**, assim como aqueles referidos pela Secretaria de Documentação –, além de ainda terem respaldo na reiterada jurisprudência do STF, dizem respeito a temas de direito material constitucional e não meramente processual. **A importância da conversão parece inegável, principalmente nos casos em que se abordam temas de diversas legislações estaduais e municipais que podem ainda não ter sido objeto de consideração ou sequer de impugnação perante o Poder Judiciário**”.

151 Com um texto muito parecido, também o art. 144, § 1.º, “a”, e § 3.º, na redação dada pela EC n. 1/69. Na primeira regra estabelece que os Tribunais de Alçada deverão observar o prescrito na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A redação da segunda regra é praticamente a mesma, só alterando a parte final.

152 Site do 1.º TAC/SP: <www.ptac.sp.gov.br/historico.htm>, acessado em 1.º.02.2005.

153 Interessante a data — **11 de agosto**. Apenas por **curiosidade** (e acho, sim, que esse tipo de informação pode fazer a diferença em banca oral), por meio da **Lei de 11 de agosto de 1827** foram criados dois cursos de *Ciências Jurídicas e Sociais*, um na cidade de *São Paulo* e outro na de *Olinda*. O art. 1.º da referida lei estabelece que durante 5 anos e em 9 cadeiras serão ensinadas as seguintes matérias: **a) 1.º ano**: 1.ª Cadeira: Direito natural, público, análise de Constituição do Império, Direito das gentes e diplomacia; **b) 2.º ano**: 1.ª Cadeira: continuação das matérias do ano antecedente; 2.ª Cadeira: Direito público eclesiástico; **c) 3.º ano**: 1.ª Cadeira: Direito pátrio civil; 2.ª

Cadeira: Direito pátrio criminal com a teoria do processo criminal; **d) 4.º ano**: 1.ª *Cadeira*: Continuação do direito pátrio civil; 2.ª *Cadeira*: Direito mercantil e marítimo; **e) 5.º ano**: 1.ª *Cadeira*: Economia política; 2.ª *Cadeira*: Teoria e prática do processo adotado pelas leis do Império. (*Fonte*: BRASIL. Leis etc. Collecção das leis do Imperio do Brazil de 1827. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1878, p. 5-7.)

154 Site do 2.º TAC/SP: <www.stac.sp.gov.br/historico.htm>, acessado em 1.º.02.2005.

155 Roberto Solimene, A extinção dos Tribunais de Alçada e a Emenda 45, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 169. Sobre a constitucionalidade da extinção dos Tribunais de Alçada, cf. interessante parecer de Clèmerson Merlin Clève, Extinção dos Tribunais de Alçada: constitucionalidade pela via da reforma constitucional no plano federal. Devida reinclusão na proposta de Emenda à Constituição n. 29, de 2000, que veicula a Reforma do Poder Judiciário, in *Reforma...*, cit., p. 159.

156 Roberto Solimene, A extinção dos Tribunais de Alçada e a Emenda 45, p. 169.

- 1 H. N. Mazzilli, *Introdução ao Ministério Público*, p. 38. Sobre a expressão *parquet*, que, do francês, significa **assoalho**, Mazzilli observa que o seu uso entre nós “... provém da tradição francesa, assim como *magistrature debout* (magistratura de pé) e *lés gens du roi* (as pessoas do rei). Os *procuradores do rei*, antes de adquirirem condição de magistrados e terem assento a seu lado, no estrado, tiveram assento sobre o assoalho da sala de audiências” (op. cit., p. 38, nota 3). Assim, enquanto a *magistratura de pé* pode ser a origem do Ministério Público, ela não se confundia com a *magistratura sentada*, quais sejam, os magistrados da época.
- 2 L. A. D. Araujo, V. S. Nunes Jr., *Curso de direito constitucional*, 13. ed., p. 409.
- 3 Para aprofundamento da matéria e críticas à escolha “inadequada” da lei ordinária, cf. H. N. Mazzilli, *Regime jurídico do Ministério Público*, Cap. 6, passim, e **RE 262.178-DF**, *Inf. 211/STF*.
- 4 Esse dispositivo constitucional foi copiado no art. 176 do **CPC/2015**, sem correspondência no CPC/73. Essa transposição das regras constitucionais para o CPC/2015 reflete a importante perspectiva, já anunciada em seu art. 1.º, de estar o processo civil **ordenado, disciplinado e interpretado** conforme os **valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil**.
- 5 Os artigos citados referem-se à Lei Orgânica do Ministério Público da União, **LC n. 75/93**, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do MPU.
- 6 Nos termos do art. 96, § 3.º, da Lei n. 9.504/97 (*que estabelece normas para as eleições*), os Tribunais Eleitorais designarão 3 **juízes auxiliares** para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Como referidas medidas são dirigidas aos Tribunais Eleitorais, a atuação ministerial se implementa pelo *Procurador Regional Eleitoral*. Os recursos contra as decisões dos *juízes auxiliares* serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
- 7 No termos do art. 118, IV, da CF/88, as **Juntas Eleitorais** são **órgãos da Justiça Eleitoral**. De acordo com o art. 36 do *Código Eleitoral* (Lei n. 4.737/65), compor-se-ão as Juntas Eleitorais de **1 juiz de direito**, que será o *presidente*, e de **2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade**, devendo os seus membros ser nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do *Tribunal Regional*, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Ainda, estabelece o art. 40 do *Código Eleitoral* ser **competência** das Juntas Eleitorais: **I** — apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas

nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição; **II** — resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração; **III** — expedir os boletins de apuração mencionados no art. 178; **IV** — expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Assim, defendendo o *regime democrático*, em todos esses atos, temos a participação do **MP Eleitoral** (trata-se de função do MPF, portanto, federal, exercida pelo MP Estadual).

8 L. C. dos S. Gonçalves, *Direito eleitoral*, p. 8 (original sem grifos).

9 L. C. dos S. Gonçalves, op. cit., p. 9.

10 José Afonso da Silva ensina não se tratar, em realidade, de “**mandato**”. Segundo o mestre, “... esse tipo de ‘mandato’ é, na realidade, mera *investidura a tempo certo*, por isso mesmo é que pode ser interrompida antes de terminar o prazo, embora não ao inteiro alvedrio da autoridade nomeante...” (art. 128, §§ 2.º e 5.º — *Curso de direito constitucional positivo*, 22. ed., p. 583).

11 Para se ter um exemplo, no Estado de São Paulo, a matéria vem disciplinada no art. 10 da LC n. 734/93, que estabelece a nomeação do Procurador-Geral de Justiça pelo Chefe do Executivo (Governador de Estado), dentre os Procuradores de Justiça integrantes da lista tríplice, que será formada pelos Procuradores de Justiça mais votados em eleição, mediante voto obrigatório, secreto e plurinominal de todos os membros do MP do quadro ativo da carreira.

12 No Estado de São Paulo, o art. 18 da LC n. 734/93 estabelece que, após a aprovação da destituição, o Colégio de Procuradores de Justiça, diante da comunicação da Assembleia Legislativa, declarará vago o cargo de Procurador-Geral de Justiça e cientificará, imediatamente, o Conselho Superior do MP para que, caso não tenha baixado as normas regulamentadoras para elaboração da lista tríplice, de acordo com o art. 10 da referida LC, expeça-as, nos termos da aludida normatização.

13 De acordo com o art. 93 da LC n. 75/93, o **Colégio de Procuradores do Trabalho**, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é **integrado** por **todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Trabalho**.

14 De acordo com o art. 95, da LC n. 75/93, o **Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho**, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição: **I** — o **Procurador-Geral do Trabalho** e o **Vice-Procurador-Geral do Trabalho**, que o integram como membros natos; **II** — **4 Subprocuradores-Gerais do**

- Trabalho**, eleitos para um mandato de 2 anos, pelo *Colégio de Procuradores do Trabalho*, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição; **III** — **4 Subprocuradores-Gerais do Trabalho**, eleitos para um mandato de 2 anos, por seus *pares*, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição.
- 15 De acordo com o art. 126 da LC n. 75/93, o **Colégio de Procuradores da Justiça Militar**, *presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar*, é **integrado** por **todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar**.
- 16 De acordo com o art. 128 da LC n. 75/93, o **Conselho Superior do Ministério Público Militar**, *presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar*, tem a seguinte composição: **I** — o **Procurador-Geral da Justiça Militar** e o **Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar**; **II** — os **Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar**.
- 17 De acordo com o art. 54 da LC n. 75/93, o **Conselho Superior do Ministério Público Federal**, *presidido pelo PGR*, tem a seguinte composição: **I** — **Procurador-Geral da República** e o **Vice-Procurador-Geral da República**, que o integram como membros natos; **II** — **4 Subprocuradores-Gerais da República** eleitos, para mandato de 2 anos, na forma do art. 53, III, permitida uma reeleição; **III** — **4 Subprocuradores-Gerais da República** eleitos, para mandato de dois anos, por seus *pares*, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição.
- 18 **SV 9/STF**: “O disposto no artigo 127 da Lei n. 7.210/1984 (*Lei de Execução Penal*) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no *caput* do artigo 58”. **CUIDADO**: deve-se observar que o julgamento da **Rcl 7.358** se deu em **24.02.2011** e, assim, antes do advento da **Lei n. 12.433, de 29.06.2011**, que, em nosso entender, ensejará a indispensável **revisão** ou **cancelamento** da referida súmula vinculante. Isso porque, se na redação original do art. 127 da LEP, na interpretação dada pelo STF, a prática de falta grave ocasionava a perda de **todos** os dias remidos, na redação atual, estabelecida pela Lei n. 12.433/2011, o juiz poderá revogar até o **limite máximo** de **1/3 do tempo remido**, observado o art. 57 (conferir se a referida súmula foi revista — **matéria pendente**. Outros comentários à referida súmula no *item 11.14.12*).
- 19 Nesse sentido, cf.: **Rcl 7.101**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.02.2011, Plenário, *DJE* de 09.08.2011; **Rcl 7.358**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24.02.2011, Plenário, *DJE* de 03.06.2011. *Em sentido contrário*, em nosso entender **superado** em razão dos precedentes citados, cf.: Rcl 4.453-MC-AgR-AgR/SE, j. 04.03.2009, *DJE* de 26.03.2009, assim como Rcl

6.541 e Rcl 6.856.

20 No mesmo sentido, cf.: Rcl 4.980-MC-AgR, Rcl 5.543-AgR, Rcl 4.931-AgR, Rcl 5.079-AgR, Rcl 5.304-ED, Rcl 6.482-MC-AgR-AgR, Rcl 5.381-ED, Rcl 4.091-AgR, Rcl 4.592-AgR, Rcl 4.787-AgR, Rcl 4.924-AgR, Rcl 4.989-AgR, Rcl 7.931-AgR. Ainda, Rcl 7.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.05.2012, Plenário, *DJE* de 26.10.2012 e Rcl 6.239-AgR-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, j. 23.05.2012, Plenário etc.

21 Cf. Hugo Nigro Mazzilli, *Regime jurídico do Ministério Público*, p. 148.

22 P. C. P. Carneiro, *O Ministério Público no processo civil e penal — promotor natural: atribuição e conflito*, 6. ed., p. 96.

23 N. Nery Junior, *Princípios do processo na Constituição Federal*, 9. ed., p. 168-169.

24 O § 2.º do art. 127 teve a sua redação alterada pela EC n. 19/98.

25 “A vitaliciedade vale muito mais que a mera estabilidade, antes concedida, porque condiciona a perda do cargo à existência de sentença judicial que a imponha; enquanto a estabilidade limita-se a garantir a realização de regular processo administrativo (LOMP, art. 38, inc. I)” (Antônio C. de Araújo Cintra et al., *Teoria geral do processo*, p. 215).

26 Cf., também, art. 15, VIII, da Lei n. 8.625/93 (ao dispor sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados) e art. 211 da Lei Complementar n. 75/93 (que dispõe sobre a organização, atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União).

27 Como já vimos, essa garantia também abrange os magistrados (art. 95, III) e ocupantes de cargos e empregos públicos, na medida em que o art. 37, XV, estabelece que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4.º; 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I.

28 *Vide* art. 28, II, da Lei n. 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Advocacia e a OAB). “A sadia proibição de exercer a advocacia vem da legislação paulista. A experiência, que sobreviveu em vários Estados, mostrou que o promotor-advogado falha na devida dedicação à sua nobre função pública e comumente dá preponderância aos interesses da banca, além de perder a indispensável imparcialidade. Aqueles que clandestinamente continuarem advogando incorrem em grave falta funcional” (A. C. A. Cintra, A. P. Grinover, C. R. Dinamarco, *Teoria geral do processo*, p. 216).

29 Cf., também, RO 999/TSE, que serviu de precedente para o voto monocrático do

Ministro Peluso, com certa particularidade, qual seja, o membro do MP já ser Deputado Federal quando do advento da EC n. 45/2004 e ter feito a opção do art. 29, § 3.º, do ADCT em outubro de 1988. No caso indicado (RO 1.070 — Fernando Capez), a manifestação pelo regime anterior se deu em 28.03.2006, e à época da promulgação da EC n. 45/2004 o recorrente exercia a função de promotor de justiça.

30 “... com isso, só para os novos integrantes da Instituição prevalece o veto aos afastamentos indiscriminados e por tempo indeterminado, para prestar serviços de qualquer natureza a órgãos do Poder Executivo. O Ministério Público não será uma Instituição realmente independente e dotada de toda a desejável postura altaneira, enquanto tais ligações não tiverem fim” (A. C. A. Cintra, A. P. Grinover, C. R. Dinamarco, *Teoria geral do processo*, p. 216).

31 Evocando os princípios da **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III), da **igualdade substancial** (art. 5.º, I), do **dever da lei de punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais** (art. 5.º, XLI), bem como a regra do art. 226, § 8.º, da CF/88, segundo a qual o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando **mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações**, o STF, dando interpretação conforme a Constituição aos arts. 12, I, e 16 da Lei n. 11.340/2006 (*Lei Maria da Penha*), estabeleceu que a ação penal para a apuração dos delitos de lesão corporal leve e culposa domésticos contra a mulher **independem de representação da vítima**. Trata-se, portanto, de **ação penal pública incondicionada** (cf. **ADC 19** e **ADI 4.424**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.02.2012, Plenário, *Inf. 654/STF*, bem como *item 19.9.5*).

32 Para uma sistematização dos conceitos sobre a **tutela dos interesses metaindividuais**, cf. Pedro Lenza, *Teoria geral da ação civil pública*, p. 40-112. Sobre o assunto, a **S. 643/STF, de 24.09.2003**: “o Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de **mensalidades escolares**”. Ainda: **a)** o STF entendeu ter o MP legitimidade para “propor ação civil pública em defesa de beneficiários do Seguro **DPVAT**, que supostamente teriam direito a diferenças de indenizações pagas em valor inferior ao previsto no art. 3.º da Lei 6.194/74” (*Tema 471 da Repercussão Geral*). Isso porque, “a tutela dos direitos e interesses de beneficiários do seguro DPVAT, **nos casos de indenização paga, pela seguradora, em valor inferior ao determinado no art. 3.º da Lei n. 6.914/1974**, reveste-se de relevante natureza social (**interesse social qualificado**), de modo a conferir legitimidade ativa ao Ministério Público para defendê-los em juízo mediante ação

civil coletiva” (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 06 e 07.08.2014, Plenário, DJE de 30.10.2014). Em razão desse entendimento, em 27.05.2015, o STJ **cancelou** a S. 470; **b) S. 329/STJ, de 02.08.2006**: “o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do **patrimônio público**”, “hipótese em que age como **substituto processual de toda a coletividade** e, conseqüentemente, na defesa de autêntico interesse **difuso**, habilitação que, de resto, não impede a iniciativa do próprio ente público na defesa de seu patrimônio, caso em que o Ministério Público intervirá como fiscal da lei, pena de nulidade da ação (art. 17, § 4.º, da Lei 8.429/1992)” (RE 208.790, j. 27.09.2000); **c) “O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos quando presente o interesse social.** No caso, Ministério Público estadual ajuizara ação civil pública em torno de certame para diversas categorias profissionais de determinada prefeitura, em que asseverara que a pontuação adotada privilegiaria candidatos os quais já integrariam o quadro da Administração Pública Municipal — v. *Informativo 545*. Salientou-se que a matéria cuidada na ação proposta teria a relevância exigida a justificar a legitimidade do Ministério Público estadual” (RE 216.443/MG, rel. orig. Min. Menezes Direito, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 28.08.2012); **d) Nesse sentido, do reconhecimento de interesse social qualificado** a legitimar o MP para a proteção de direitos individuais homogêneos em ações coletivas, destacamos, além das hipóteses elencadas acima, os seguintes julgados e temas: **d.1) AI 637.853 AgR/SP**: contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação; **d.2) AI 606.235 AgR/DF**: contratos de *leasing*; **d.3) RE 475.010 AgR/RS**: interesses previdenciários de trabalhadores rurais; **d.4) RE 328.910 AgR/SP**: aquisição de imóveis em loteamentos irregulares; **d.5) RE 514.023 AgR/RJ**: diferenças de correção monetária em contas vinculadas ao FGTS.

33 A Res. n. 118/2014-CNMP (DOU de 27.01.2015), de modo bastante avançado, dispõe sobre a **Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público**. De acordo com o seu art. 1.º, parágrafo único, ao Ministério Público brasileiro incumbe implementar e adotar mecanismos de **autocomposição**, como a **negociação**, a **mediação**, a **conciliação**, o **processo restaurativo** e as **convenções processuais**, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão sobre tais mecanismos.

34 Nos termos do art. 17, § 1.º, da Res. n. 14, de 06.11.2006, “a prova preambular **não poderá ser formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais**. As opções consideradas corretas deverão ter embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos

Tribunais Superiores”. Nesse sentido, também, a Res. n. 75/2009 do CNJ. Muito bem-vinda a regra que fortalece o que temos dito a todos os “concurseiros” do Brasil: fiquem atentos à jurisprudência dos Tribunais. Leiam informativos e notícias dos Tribunais. Esta é a nossa “luta” constante em manter o “nosso” **Esquematizado®** sempre atualizado.

35 No mesmo sentido, cf.: **HC 91.661**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.03.2009, 2.^a T., *DJE* de 03.04.2009; **HC 89.837**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2009, 2.^a T., *DJE* de 20.11.2009; **HC 93.930**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.12.2010, 2.^a T., *DJE* de 03.02.2011.

36 Recomendamos a leitura do **HC 84.548**, j. 04.03.2015, Pleno, *DJE* de 10.04.2015, envolvendo fatos relacionados ao homicídio do então prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, e o tema da investigação pelo MP.

37 O nosso ilustre e incansável leitor pode encontrar o inteiro teor da referida *resolução* no site do **CNMP**: <<http://www.cnmp.mp.br/portal/normas>>.

38 Cabe alertar que a 1.^a T. do STF entendeu que “a competência revisora conferida ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) limita-se aos processos disciplinares instaurados contra os **membros do Ministério Público da União ou dos Estados** (inciso IV do § 2.^o do art. 130-A da CR), **não sendo possível a revisão de processo disciplinar contra servidores**. (...). A CR resguardou o CNMP da possibilidade de se tornar instância revisora dos processos administrativos disciplinares instaurados nos órgãos correcionais competentes contra servidores auxiliares do Ministério Público em situações que não digam respeito à atividade-fim da própria instituição” (**MS 28.827**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.08.2012, 1.^a T., *DJE* de 09.10.2012).

39 Nesse sentido manifestou-se o STF ao analisar dispositivos da Lei n. 8.443/92: “... O Ministério Público junto ao TCU não dispõe de fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores pela própria Constituição (art. 130), encontra-se consolidado na *intimidade estrutural* dessa Corte de Contas, que se acha investida — até mesmo em função do poder de autogoverno que lhe confere a Carta Política (art. 73, *caput*, *in fine*) — da prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concernente à sua organização, à sua estruturação interna, à definição do seu quadro pessoal e à criação dos cargos respectivos” (STF, Pleno, ADI 798-1-DF, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 19.10.1994).

40 Como visto, não se pode esquecer que essa **previsão de advocacia** por parte dos **membros do MPF** foi **temporária**, até a edição da **lei complementar**, já que, antes do

surgimento da Advocacia-Geral da União, essa atribuição, no regime anterior, ficava ao encargo do Ministério Público (cf. *item 12.2.7.3*). Nesse sentido, o art. 29, § 2.º, do ADCT estabeleceu que aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será **facultada** a opção, de **forma irretratável**, entre as carreiras do **Ministério Público Federal** e da **Advocacia-Geral da União**, situação essa regulamentada no art. 61 da LC n. 73/93 e no art. 282 da LC n. 75/93.

41 Conforme anotou André Ramos Tavares, a *procuradoria municipal* “... não foi contemplada pela Constituição como instituição obrigatória (até rendendo-se à realidade de municípios que não teriam como arcar com um quadro de advogados públicos permanentes)” (*Curso de direito constitucional*, 8. ed., p. 1.356).

42 O. A. B. de Mello, *Princípios gerais de direito administrativo*, 3. ed., p. 584.

43 Cf. **MS 24.631**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 09.08.2007, Plenário, *DJ* de 1.º.02.2008.

44 M. S. Z. Di Pietro, *Direito administrativo*, 23. ed., p. 231.

45 **ADI 2.652**, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08.05.2003, Plenário, *DJ* de 14.11.2003. O tema foi revisto e **confirmado** pelo STF no julgamento das **Rcl 5.133** e **7.181** (j. 20.05.2009, Pleno).

46 Trata-se da Lei Complementar n. 73, de 10.02.1993, que institui a **Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União** e dá outras providências.

47 Entendemos que essa representação da União se implementa não apenas no plano interno mas, também, no **internacional**, por exemplo, nos processos em que o Brasil é parte perante a **Corte Interamericana de Direitos Humanos**.

48 Nesse sentido, cf. os agravos regimentais nos MS 25.962, 28.499, 28.805 e 30.736, j. 11.04.2013.

49 Nesse sentido, também se posicionou o STF no julgamento do **Inq. 1.660-QO**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.09.2000, Plenário, *DJ* de 06.06.2003.

50 No mesmo sentido, cf. **ADI 242**, Rel. Min. Paulo Brossard, j. 20.10.1994, Plenário; **ADI 3.522**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.10.1994, Plenário; **ADI 1.254-AgR**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14.08.1996, Plenário; **ADI 1.434-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.08.1996, Plenário (sustentando, inclusive, que essa atuação processual plenamente vinculada, no sentido de assumir, “na condição de garante e curador da presunção de constitucionalidade, a defesa **irrestrita** da validade jurídica da norma impugnada”, seria,

inclusive, um mecanismo de se assegurar o postulado do contraditório, no processo de controle abstrato de constitucionalidade).

51 No mesmo sentido: **ADI 2.101**, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 18.04.2001, Plenário; **ADI 3.121**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.03.2011, Plenário; **ADI 4.270**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.03.2012, Plenário.

52 No mesmo sentido: **ADIs 2.376, 2.906 e 3.674**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.º.06.2011, Plenário.

53 Entrevista concedida pelo AGU Luís Inácio Lucena Adams (28.07.2013): <<http://www.conjur.com.br/2013-jul-28/entrevista-luis-inacio-lucena-adams-advogado-geral-uniao>>, acesso em 30.01.2014.

54 Para aprofundamento da matéria, até o *fechamento desta edição*, vigoravam as regras sobre competência da PGFN contidas, também, nos seguintes dispositivos: **a)** Decreto-lei n. 147/67; **b)** art. 9.º do Anexo I do Decreto n. 7.482/2011, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da Fazenda e reproduz o texto do art. 1.º do anexo do *Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional*, aprovado pela Portaria MF n. 36/2014.

55 Destacamos a **S. 644/STF**: “Ao titular do cargo de Procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo”.

56 Nesse sentido, a 2.ª T. do STF já se manifestou no julgamento do **RE 345.458**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.02.2005, 2.ª T, *DJE* de 11.03.2005.

57 **ADI 4.261**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 02.08.2010, Plenário, *DJE* de 20.08.2010.

58 A. R. Tavares, *Curso de direito constitucional*, 8. ed., p. 1.356.

59 Cassio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado*, p. 102.

60 O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB. A atividade de advocacia é exercida (seguindo as regras do Estatuto e do regime próprio de cada carreira) pelos integrantes da Advocacia-Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional (art. 3.º do Estatuto da OAB).

61 Observar, contudo, serem **nulos** os atos privativos de advogado praticados por pessoa

não inscrita na OAB, bem como os atos praticados por advogado impedido, suspenso, licenciado, ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia (art. 4.º do Estatuto da OAB).

62 As regras definidas no *Estatuto da Advocacia e a OAB*, seu *Regulamento Geral* e *Código de Ética e Disciplina da OAB* deverão ser estudadas para enfrentar as questões do **Exame de Ordem Unificado**.

63 Cf. *Inf. 427/STF* e *Notícias STF*, 17.05.2006 — 20h59.

64 **Cuidado:** segundo orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do **HC 86.834/SP** (j. 23.08.2006, v. *Inf. 437/STF*), o STF não mais é competente para processar e julgar *habeas corpus* impetrado contra ato de turma recursal de juizado especial criminal, estando, assim, **superada** a S. 690/STF (cf. *item 11.6.4.3*).

65 Sobre o tema, cf. aprofundamento no *item 12.5.1.3*.

66 Cf. **ADI 1.127**, Rel. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.05.2006, Plenário, *DJE* de 11.06.2010. Para quem se animar, o acórdão tem **201 páginas** — o quadro resumo é a Ementa do acórdão.

67 Nessa data, houve pedido de vista do Min. Dias Toffoli. O mérito, contudo, não foi apreciado, por entender, a maioria da Corte, não se tratar de hipótese para o cabimento da reclamação (j. 18.03.2015). Devemos aguardar novo pronunciamento do Pleno para enfrentar a discussão sobre a revogação ou não do art. 7.º, V, da Lei n. 8.906/94 pela Lei n. 10.258/2001 (*pendente*). Em seu voto, em *obiter dictum*, o Min. Dias Toffoli ponderou: “assim, penso, em conformidade com o que igualmente expôs o ilustre Procurador-Geral da República, que tal como se dá em relação aos Magistrados e Membros do Ministério Público, na hipótese de **prisão provisória**, devem ser asseguradas aos advogados instalações condignas com o seu grau, **sejam elas em estabelecimento castrense ou não**, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, em ambiente que não seja guarnecido com grades e outros dispositivos ostensivos de contenção, que eventualmente se equiparem a uma cela. Com isso, certamente, estará atendida a *ratio* da lei e assegurada aos integrantes da advocacia, se provisoriamente presos, dignidade idêntica àquela desfrutada pelas mais altas autoridades da República”.

68 Este estudo sobre a **Defensoria Pública** teve por base o nosso trabalho “Assistência jurídica, integral e gratuita e o fortalecimento da defensoria pública na reforma do

judiciário”, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 489.

69 M. Cappelletti e B. Garth, *Acesso à justiça*, p. 8 (tradução e revisão de Ellen Gracie Northfleet do original *Access to Justice: the worldwide movement to make rights effective. A general report*, Milano: Giuffrè, 1978). Em outro estudo, Cappelletti também discorre sobre as **3 ondas renovatórias** (cf. M. Cappelletti, *Accesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, *Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia* 12/309-21, passim, especialmente a partir da p. 316).

70 M. Cappelletti e B. Garth, *Accesso alla giustizia*, p. 31.

71 J. C. Barbosa Moreira, O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo, *RePro* 67/130.

72 Para aqueles que forem prestar o concurso de Defensor, indispensável a sua leitura. Os concursos específicos exigem o conhecimento das regras lá contidas. Outrossim, aqueles que forem prestar concurso para Defensorias Estaduais, deverão ter conhecimento das leis complementares de cada Estado, bem como da lei complementar que regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal.

73 Destaque-se, dentre tantas, a excelência da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pioneira no Brasil e América Latina (1954) e a do Rio Grande do Sul (1968) e Mato Grosso do Sul (1982). Vários Estados, após a EC n. 45/2004, vêm, paulatinamente, implantando as suas defensorias.

74 Conforme o art. 3.º da **EC n. 69/2012**, o Congresso Nacional e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, imediatamente após a promulgação da referida emenda e de acordo com suas competências, instalarão comissões especiais destinadas a elaborar, em 60 dias, os projetos de lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria nela tratada.

75 “Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da **Defensoria Pública**, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, **em duodécimos**, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.º” (original sem grifos).

76 Para leitura do relevante trabalho de Sarmiento, cf.

<http://www.anadef.org.br/images/042015/Parecer_Autonomia_DPU_Daniel_Sarmiento.pdf>, acesso em: 20.04.2015.

77 Adriana Fagundes Burger, Patrícia Kettermann, Sérgio Sales Pereira Lima (Org.), *Defensoria Pública [recurso eletrônico]: o reconhecimento constitucional de uma metagarantia*, passim, acesso em: 20.04.2015.

78 O estudo é do ano de 2013 (os dados analisados na pesquisa foram coletados entre os meses de setembro/2012 e fevereiro/2013). Para relatório completo: <http://www.anadep.org.br/wtksite/mapa_da_defensoria_publica_no_brasil_impresso_.pdf>, acesso em: 20.04.2015. Os números devem ser acompanhados e servem de importante trincheira de batalha na consolidação dessa carreira tão importante para o país (estima-se que, segundo os dados do IBGE/2010, 82% dos brasileiros — com renda de até 3 salários mínimos, ao menos em tese, dependem do trabalho desses **combatentes, vocacionados e incansáveis** advogados). No fechamento desta edição, estavam em andamentos alguns concursos públicos no âmbito estadual, bem como para DPU (neste caso, o edital com data de 31.12.2014, para o preenchimento de 58 vagas — contando a DPU com 555 defensores).

79 “Lei 8.742, de 30-11-2005 do Estado do Rio Grande do Norte, que ‘dispõe sobre a contratação temporária de advogados para o exercício da função de defensor público, no âmbito da Defensoria Pública do Estado’. A Defensoria Pública se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciárias, de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça (inciso XXXV do art. 5.º da CF/1988). Por desempenhar, com **exclusividade**, um mister estatal genuíno e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não convive com a possibilidade de que seus agentes sejam recrutados em caráter precário. Urge estruturá-la em **cargos de provimento efetivo** e, mais que isso, cargos de **carreira**. A estruturação da Defensoria Pública em cargos de carreira, providos mediante **concurso público de provas e títulos**, opera como garantia da independência técnica da instituição, a se refletir na boa qualidade da assistência a que fazem jus os estratos mais economicamente débeis da coletividade” (**ADI 3.700**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15.10.2008, Plenário, *DJE* de 06.03.2009). *Em igual sentido*, destaca-se a complicada realidade do **Estado de Santa Catarina**, cujo art. 104 da Constituição fez a previsão de Defensoria Pública a ser exercida por *Defensoria Dativa e Assistência Judiciária Gratuita*, nos termos da LC estadual n. 155/97, que estabeleceu **convênio com a seccional da OAB/SC** para prestação dos serviços de “defensoria pública dativa”. Naturalmente, o STF declarou inconstitucional essa previsão e, modulando

os efeitos da decisão, determinou a implementação da **carreira**, por **concurso público**, como determina a Constituição, dentro do prazo de 1 ano a contar da decisão (**ADI 3.892** e **ADI 4.270**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.03.2012, Plenário, *DJE* de 25.09.2012). Para mais detalhes, cf. *item 12.6.9.17*.

80 “Este Tribunal, interpretando o art. 22 do ADCT, entendeu que servidores investidos na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte têm **direito à opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária, desde que cumpridos os requisitos definidos pelo texto constitucional**. Precedentes. As Constituições estaduais não podem ampliar a excepcionalidade admitida pelo art. 22 do ADCT da CF/1988” (**ADI 3.603**, Rel. Min. Eros Grau, j. 30.08.2006, Plenário, *DJ* de 02.02.2007). No mesmo sentido: ADI 1.199, ADI 112, ADI 175, RE 161.712-ED, AI 407.683-AgR etc.

81 Até porque é o Procurador do Estado quem tem a função de representar o Estado e, assim, se no exercício regular de direito, parece razoável que o Estado tenha o interesse de “defender” o ato praticado por seu servidor, que, no fundo, acaba sendo um ato inerente ao próprio Estado.

82 A prerrogativa da intimação pessoal foi reconhecida pelo STF inclusive para a intimação de acórdão proferido em *habeas corpus* pelo STJ — *Inf. 276/STF*, tendo sido citados os seguintes precedentes: HC 79.954-SP (*DJU* de 28.04.2000); HC 80.103-RJ (*DJU* de 25.08.2000); HC 80.104-RJ (*DJU* de 15.03.2002). HC 81.958-RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, 06.08.2002. **Em sentido contrário:** HC 77.385-MG (*DJU* de 07.05.1999) e HC 68.884-PR (*DJU* de 05.03.1993). HC 79.866-RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, 28.03.2000.

83 Em relação ao rito específico dos Juizados, confira regras apresentadas no *item 6.7.1.6.1.1*.

84 Cf. precedentes citados: HC 73.310-SP (*DJU* de 17.05.1999) e HC 79.867-RS (*DJU* de 20.10.2000). HC 81.342-SP, Rel. Min. Nelson Jobim, 20.11.2001. Em relação aos Juizados Especiais, cf. *itens 12.3.6.9 e 12.6.9.6*.

85 Art. 370, § 4.º: “A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal”.

86 Nesse sentido: “não é nulo o julgamento de apelação sem a intimação pessoal de defensor dativo, nos casos anteriores à entrada em vigor da Lei 9.271/1996” (RHC 88.512, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 09.03.2010, 2.ª Turma, *DJE* de 23.04.2010).

87 O art. 14, *caput*, da Lei n. 10.259/2001 (que dispõe sobre a instituição dos Juizados

Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) estabelece que caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. O Regimento Interno da *Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais* está disciplinado na **Res. n. 22/2008-CJF**. Referida resolução pode ser encontrada no site do Conselho da Justiça Federal: <<http://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/3835>>.

88 *Notícias STJ*, 24.11.2004, relatando o desfecho do Processo n. 2003.40.00.706363-7. O referido recurso foi julgado em 31.08.2004, tendo sido interposto recurso para o STJ e o STF. Assim, devemos acompanhar, já que se trata de decisão da *Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais*, e não de decisão pacificada dos Tribunais Superiores. Provavelmente referido recurso especial não será conhecido, tendo em vista o teor da **S. 203/STJ** (com a redação fixada no julgamento do AgRg no Ag 400.076-BA, na sessão de 23.05.2002): “não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais”. Em relação ao RExtr, o STF já se posicionou sobre a questão da intimação pessoal; vamos aguardar em relação ao prazo em dobro.

89 *Inf. 362/STF*, 20-24.09.2004. Precedentes citados: HC 71.642/AP (*DJU* de 21.10.1994); HC 81.281/MS (*DJU* de 22.03.2002); HC 81.446/RJ (*DJU* de 10.05.2002).

90 Conforme anotou Scarpinella Bueno, “a previsão de convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil para este fim, constante do Projeto do Senado, acabou sendo eliminada na última etapa dos trabalhos legislativos” (in: *Novo código de processo civil anotado*, p. 160).

91 “Por entender caracterizada a ofensa ao art. 134 da CF, que veda aos membros da Defensoria Pública o desempenho de atividades próprias da advocacia privada, o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta proposta pelo Procurador-Geral da República para declarar a inconstitucionalidade do art. 137 da Lei Complementar 65/2003, do Estado de Minas Gerais, que permite que os defensores públicos exerçam a advocacia fora de suas atribuições institucionais até que sejam fixados os subsídios dos membros da carreira. Afastou-se, ainda, o argumento de se inferir, da interpretação sistemática do art. 134 c/c o art. 135 e o § 4.º do art. 39, da CF, que o exercício da advocacia pelos defensores públicos estaria proibido apenas após fixação dos respectivos subsídios, visto que tal assertiva conduziria à conclusão de que a vedação trazida pelo art. 134, texto normativo constitucional originário, teria sido relativizada com a EC 19/98, que introduziu o

art. 135 e o § 4.º do art. 39. Asseverou-se, ainda, a vigência da Lei Complementar 80/94 — que organiza a Defensoria Pública da União, do DF e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados-membros — que também prevê a aludida vedação. ADI 3.043/MG, Rel. Min. Eros Grau, 26.04.2006” (*Inf.* 424/STF).

92 Nesse sentido: “esta Corte firmou entendimento segundo o qual o Ministério Público do Estado de São Paulo tem legitimidade para ajuizar ação em favor dos hipossuficientes até que a Defensoria Pública estadual tenha plena condição de exercer seu múnus” (**RE 432.423**, Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJ* de 07.10.2005). Cf., ainda, RE 135.328 e RE 147.776.

93 O tema também está sendo discutido no **ARE 690.838** (ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais em defesa de interesses e direitos difusos) que, certamente, deverá adotar o entendimento fixado na **ADI 3.943** (pendente). No mesmo sentido, o mérito da **ADI 558-MC** (cautelar julgada em 16.08.1991, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, *DJ* de 26.03.1993).

94 Devemos estar sempre preocupados com o aforismo que se tornou um alerta quando se trata da problemática do *acesso à Justiça*: “In England, Justice is open to all, like the Ritz Hotel” — “Na Inglaterra, a Justiça está aberta a todos, como o Ritz Hotel” — hotel de luxo (James Mathew 1830-1908, citado em R. E. Megarry *Miscellany-at-Law*, 1955).

95 Para aprofundamento dos exemplos, sugerimos a análise dos *I e II Relatórios Nacionais de Atuações Coletivas da Defensoria Pública*, elaborados pela Associação Nacional dos Defensores Públicos — ANADEP (2013 e 2015).

96 Como bem lembrou Benjamin, a ideia do “carona” (*free rider*) quer significar a situação em que alguém “... sem qualquer esforço pessoal, é beneficiado — reflexa e gratuitamente — de atividade alheia. Veja-se a hipótese de algumas pessoas, todas morando às margens de um lago, que resolvem investir maciçamente na sua despoluição. No instante em que suas águas cristalinas estejam de volta, ninguém pode impedir que outros cidadãos (os moradores das ruas interiores) passem a ser beneficiados — reflexa e gratuitamente — pelo esforço daquele grupo de cidadãos operosos. A se negar o benefício a um cidadão apenas — provocando-se nova poluição, por exemplo — todos sofrem concomitantemente, a mesma exclusão” (cf., Richard B. McKenzie e Gordon Tullock, *Modern political economy: an introduction to economics*, New York, McGraw Hill Book Company, New York, 1978, p. 448, apud A. H. de V. Benjamin e (Coord.), *Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão*, p. 61).

97 HC 92.399, Rel. Min. Ayres Britto, j. 29.06.2010, 1.^a Turma, *DJE* de 27.08.2010.

98 Cabe lembrar que o **Edital n. 1/2012**, publicado em 09.10.2012, abriu inscrições para o *1.º Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado de Santa Catarina*, para o provimento de cargos da Classe inicial da Carreira de Defensor Público do Estado de Santa Catarina — Terceira Categoria, homologado em 15.03.2013. Ainda, interessante acompanhar a **Rel 16.034** ajuizada em 17.07.2013 pela *Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP)*, em que se alega descumprimento de decisão da Suprema Corte, pois a lei complementar estadual fez previsão de apenas 60 cargos para uma demanda total de 509 cargos necessários no Estado, de acordo com estudo constante do *Mapa da Defensoria Pública do Brasil*, elaborado pelo *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)*. O Rel. Min. Celso de Mello, em 19.12.2013, negou o pedido de liminar (*DJE* de 03.02.2014).

99 Como veremos, algumas questões de Direito Constitucional nas provas do Ministério Público exigem vasto conhecimento das Leis Orgânicas. Assim, deve o candidato ao Ministério Público estudar, com muita atenção, tanto a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93) como a Lei Complementar do Estado, no caso de São Paulo, a Lei Complementar n. 734/93. Para provas do Ministério Público da União, completar o estudo com a Lei Complementar n. 75/93. Para a Defensoria Pública, indispensável a leitura da LC n. 80/94, alterada pela LC n. 98/99, e, se a prova for para a Defensoria Estadual ou do DF e Territórios, a LC local específica. O mesmo vale para as outras carreiras, no tocante aos Estatutos próprios e Leis Orgânicas. Para os candidatos à OAB, pelo menos no Estado de São Paulo, as questões específicas da carreira são cobradas na parte de Ética, e não em Constitucional. É muito pouco provável, por exemplo, que as questões a seguir expostas referentes ao Ministério Público (a parte específica, é claro) sejam cobradas na prova da OAB ou Magistratura (por razões óbvias), devendo, então, o candidato poupar esforços em questões que envolvam leis orgânicas de outras carreiras. Devemos **focalizar** o estudo, que deverá ser feito, acima de tudo, com **estratégia!**

- 1 Sobre o **sistema constitucional das crises**, há um interessante trabalho de Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira, apresentado na PUCSP, em 2008, como tese de doutorado e publicado pela Editora Método (*Sistema constitucional das crises: restrições a direitos fundamentais*, passim).
- 2 Cf. José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 2. ed., p. 617.
- 3 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, cit.
- 4 Aricê Moacyr Amaral Santos, *O estado de emergência*, p. 32 (grifamos).
- 5 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 617-618.
- 6 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 621.
- 7 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, 20. ed., p. 740 (grifamos).
- 8 Cf. Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 315.
- 9 A gravidade é tamanha que, na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, a constituição federal **não** poderá ser **emendada** (art. 60, § 1.º).
- 10 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, p. 311.
- 11 Interessante notar que a Constituição do Império, de 1824, fala somente em **forças do mar** e da **terra**. Isso porque, cabe lembrar, o avião só irá surgir na primeira década do século XX.
- 12 Para conhecimento da **hierarquia militar** nas Forças Armadas, cf. *item 11.8.6.2.3*.
- 13 Para as provas, sugerimos uma leitura atenta dos aludidos dispositivos. Notadamente em relação à discussão sobre a **perda do posto** e da **patente** (art. 142, § 3.º, VI e VII), assim como da **graduação**, indispensável a leitura do *item 11.8.6.3.3*. Interessante, ainda, para aprofundamento, a leitura dos *itens 11.8.6* e seguintes, que tratam da **Justiça Militar** e explicam detalhes sobre as **Forças Armadas**.
- 14 A **Lei n. 13.109/2015** dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, as medidas de proteção à maternidade para militares grávidas e a licença-paternidade, no **âmbito das Forças Armadas**.
- 15 O brasileiro que **não se apresentar para a seleção** na data prevista para a fixação do

contingente de sua classe ou que, tendo-o feito, **ausentar-se** sem a ter completado, será considerado **refratário** (art. 24 da Lei n. 4.375, de 17.08.1964). Já o convocado selecionado e designado para incorporação, ou matrícula, que não se apresentar à Organização Militar que lhe for designada dentro do prazo marcado, ou que, tendo-o feito, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação ou matrícula, será declarado **insubmisso** (art. 25 da referida lei). O que abandona o serviço militar é considerado **desertor**.

16 De acordo com o art. 3.º, § 2.º, da **Lei n. 8.239/91**, entende-se por Serviço Militar Alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar. O art. 3.º, § 3.º, da referida lei, por seu turno, fixa que o Serviço Alternativo será prestado em organizações militares da ativa e em órgãos de formação de reservas das Forças Armadas ou em órgãos subordinados aos Ministérios Cíveis, mediante convênios entre estes e os Ministérios Militares, desde que haja interesse recíproco e, também, sejam atendidas as aptidões do convocado. Ao final do período de atividade previsto no § 2.º do art. 3.º da lei, será conferido **Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigatório**, com os mesmos efeitos jurídicos do **Certificado de Reservista** (art. 4.º).

17 Conforme estudamos no *item 17.4.3.1*, alertamos que a maioria dos autores de direito eleitoral vem estabelecendo a **recusa** como situação de **suspensão**, e não perda de direitos políticos, nos termos da **literalidade** do art. 4.º, § 2.º, da Lei n. 8.239/91.

18 José Afonso da Silva entende que a fixação ou modificação dar-se-á em tempo de paz, pois, “em tempo de guerra, não se cuidará propriamente de efetivos, mas de **mobilização nacional**, compreendida a convocação de reservistas e de outras forças militares, o que se faz por decreto do Presidente da República (art. 84, XIX)” (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 655 — destacamos).

19 Art. 61, § 1.º, I e II, “F” (alínea “F” acrescentada pela EC n. 18/98). Como exemplo de modificação das Forças Armadas (no caso o Exército), destacamos a **Lei n. 12.918/2013**, de iniciativa da **Presidente Dilma Rousseff**.

20 Aguardamos eventual sugestão ou indicação de precedente, agradecendo a contribuição do nosso ilustre leitor. Fique à vontade para encaminhar mensagem para o e-mail: pedrolenza@terra.com.br.

21 A LC n. 97/99 foi modificada pela LC n. 117/2004 e pela LC n. 136/2010.

22 O **Conselho Militar de Defesa** é composto pelos Comandantes da Marinha, do

Exército e da Aeronáutica (lembrar que os respectivos Ministérios foram transformados em Comandos, com a criação do **Ministério da Defesa** pela **EC n. 23/99**) e pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tendo por integrante e Presidente o Ministro de Estado da Defesa.

23 Como já vimos, o **Ministério da Defesa** foi criado pela EC n. 23/99.

24 *Direito administrativo*, p. 94.

25 “Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, **devem seguir o modelo federal**. O art. 144 da Constituição aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública. Entre eles não está o Departamento de Trânsito. Resta pois **vedada aos Estados-Membros a possibilidade de estender o rol**, que esta Corte já firmou ser *numerus clausus*, para alcançar o Departamento de Trânsito” (**ADI 1.182**, voto do Rel. Min. Eros Grau, j. 24.11.2005, Plenário, *DJ* de 10.03.2006. No mesmo sentido: *ADI 2.827*, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2010, Plenário, *DJE* de 06.04.2011; *ADI 236*, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 07.05.1992, Plenário, *DJ* de 1.º.06.2001).

26 *Comentário contextual à Constituição*, 8. ed., p. 650.

27 O art. 3.º da referida lei considera **atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio**: **a)** o policiamento ostensivo; **b)** o cumprimento de mandados de prisão; **c)** o cumprimento de alvarás de soltura; **d)** a guarda, a vigilância e a custódia de presos; **e)** os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade; **f)** o registro de ocorrências policiais.

28 Cf. *Notícias MJ*, 02.06.2006.

29 Alguma outra informação pode ser obtida em: <www.upp.rj.gov.br>.

30 Interessante observar que o constituinte utilizou a expressão ordem **política**, e não ordem **pública** como consta do *caput* do art. 144.

31 Nessas hipóteses, de acordo com a **Lei n. 10.446, de 08.05.2002**, poderá o **Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça**, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da CF/88, em especial das polícias militares e civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais: **sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro** (arts. 148 e 159 do CP), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima; **formação de cartel**

(incisos I, “a”, II, III e VII do art. 4.º da Lei n. 8.137/90); relativas à **violação a direitos humanos**, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; **furto, roubo ou receptação de cargas**, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado da Federação. Trata-se de **rol exemplificativo** previsto no art. 1.º da lei, já que, conforme o seu parágrafo único, atendidos os pressupostos do *caput*, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de **outros casos**, desde que tal providência seja **autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça**.

32 Essa disposição foi introduzida pela Lei n. 13.034/2014, fruto de conversão da MP n. 650/2014. Na Mensagem n. 184, encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, encontramos a lógica dessa previsão que, aparentemente, não trazia novidades, já que, desde 1996, para todos os cargos da carreira policial, exigia-se o nível superior. Vejamos: “a proposta busca **registrar** em texto legal que todos os **cargos** da **Carreira Policial** são de **nível superior**. Tal questão se refere mais especificamente aos cargos de **Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal**, para os quais, desde a edição da Lei n. 9.266, de 15 de março de 1996, é exigido curso superior para ingresso. Entretanto, os cargos se mantêm legalmente como sendo de nível intermediário. O Decreto-Lei n. 2.320, de 26 de janeiro de 1987, que tratou do ingresso nas categorias funcionais da Carreira Policial Federal dispôs, em seu art. 2.º, que ‘as categorias funcionais de Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal são classificadas como categorias de nível médio’. Esta situação não foi alterada em legislação posterior que reestruturou a Carreira Policial Federal, a supracitada Lei n. 9.266, de 1996”.

33 Estamos nos referindo à MP n. 657/2014, convertida na Lei n. 13.047/2014, que introduziu novas regras à Lei n. 9.266/96 que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal.

34 Em outubro de 2014, em oposição à **MP n. 657**, a *Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF)* anunciou paralisação de escrivães, papiloscopistas e agentes (os EPAs). Conforme noticiado à época, “em tramitação no Congresso, a MP 657 (que foi convertida na Lei n. 13.047/2014, acrescente-se) foi recebida pela categoria como uma reedição da **PEC-37**, que dá poderes exclusivos à Polícia para realizar investigações criminais, limitando o poder do Ministério Público e alimentando o corporativismo dentro da PF” (Notícia de 21.10.2014, em <<http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/45446>>,

acesso em 08.01.2015). Em 21.10.2014, a Min. Assusete Magalhães, do STJ, nos autos da **PET 10.484** (2014/0108388-0), reforçou a proibição de paralização da categoria, reiterando decisão liminar proferida em 13.05.2014, aumentando o valor da multa, fixada a título de *astreintes*, de R\$ 200.000,00 para R\$ 500.000,00 por dia de descumprimento.

35 Informações retiradas da *Revista Prima*, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), n. 79/80, jul.-dez. 2014, p. 55. Observamos que a *OAB São Paulo*, à época da MP

n. 657, lançou nota apoiando, em sua integralidade, as novidades. Por outro lado, o MPF apresentou Nota Técnica da 7.^a Câmara de Coordenação e Revisão sobre referida MP expressando explícito posicionamento contrário à sua aprovação (confira os dois documentos em: <<http://www.conjur.com.br/2014-nov-12/mp-delegados-policia-federal-opoe-promotores-advocacia>>, acesso em 08.01.2015).

36 Cabe observar que, até o fechamento desta edição, ainda **não havia regra explícita** sobre o **prazo** do **mandato** do Delegado-Geral, o **processo oficial de escolha** e a **forma de sua destituição**. Diante dessa realidade, os **Delegados de Polícia Federal**, reunidos no **VI Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal**, convocado pela *Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal — ADPF*, realizado em Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, nos dias 02 a 05.04.2014, com o propósito de discutir “Os desafios da Polícia Federal para o enfrentamento ao Crime Organizado”, **elaboraram 15 propostas** em uma **declaração pública de encerramento** e que foram encaminhadas ao Presidente da República, destacando-se, sobre o tema em análise, a de n. 5, nos seguintes termos: “Os Delegados de Polícia Federal irão eleger seu Diretor-Geral, cargo privativo de Delegado de Polícia Federal posicionado na última classe da carreira, que passará a ser denominado ‘Delegado-Geral de Polícia Federal’, por votação direta e secreta, mediante processo eleitoral conduzido pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, cuja lista tríplice será encaminhada ao Ministro da Justiça e dele para a Presidência da República para indicação. O prazo do mandato do Delegado-Geral, o processo oficial de escolha e a forma de destituição serão previstos em lei”. Até que haja alguma definição normativa, a classe vem tentando instituir esse modelo de **participação na escolha**, como se verifica, para se ter um exemplo, em outras carreiras, no âmbito do Ministério Público. Nesse sentido, no final de 2014, os delegados federais, por iniciativa da *Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF)* e da *Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (FENADEPOL)*, formaram uma **lista tríplice informal** e a encaminharam ao Ministério da Justiça e à Presidência da

República.

37 Comentário ao art. 144, in: J. J. Gomes Canotilho e outros, *Comentários à Constituição do Brasil*, p. 1.588. Interessante texto sobre o histórico das ferrovias no Brasil, do seu auge à sua decadência, verificada no período de 1980 a 1992, até o processo de **desestatização** da Rede Ferroviária Federal S.A. — RFFSA (Lei n. 8.987/95), pode ser lido em <<http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp>>, acesso em 1.º.05.2015.

38 **Lei n. 11.438/91/GO**: “Art. 6.º Fica criado o cargo de Diretor-Geral da Polícia Civil, de provimento em comissão. Parágrafo único. O Diretor-Geral da Polícia Civil, com atribuições definidas em Decreto: a) é nomeado e exonerado pelo Governador dentre os delegados de polícia de carreira, **da classe mais elevada**, de conformidade com o art. 123 da Constituição Estadual”.

39 Segundo Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, “isso significa que em caso de estado de emergência ou estado de sítio, ou em decorrência de uma guerra, os integrantes destas corporações poderão ser requisitados pelo Exército para exercerem funções diversas da área de segurança pública” (cf. <www.militar.com.br/legisl/artdireitomilitar/ano2003/pthadeu/forcaspoliciais-sistemaconstitucional.htm>). No referido site (<www.militar.com.br>, no item “direito militar”), o autor, que é juiz-auditor substituto na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, traz vários artigos de altíssimo conteúdo sobre questões relacionadas à Justiça Militar. Para os concursos, especialmente aqueles mais específicos, vale conferir! Cf., ainda, os sites do TJM de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente: <www.tjmsp.jus.br> e <www.tjmmg.jus.br>.

40 Sobre a questão específica de aplicação da pena de perda do posto e da patente (oficiais) e da graduação (praças), cf. discussão no *item 11.8.6.3.3*. Ainda, recomendamos a leitura de todo o *item 11.8.6* para aprofundamento em relação aos Militares.

41 Nesse sentido, cf. *RTJ* 153/116, Rel. Min. Marco Aurélio; *RTJ* 165/500-501, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti; ADI 2.102/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 207.440/DF, Rel. Min. Sydney Sanches; RE 207.627-ED/DF, Rel. Min. Néri da Silveira; RE 209.161/DF, Rel. Min. Moreira Alves; RE 215.828/DF, Rel. Min. Sydney Sanches; RE 218.479/DF, Rel. Min. Moreira Alves; RE 221.693/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, *DJU* de 13.06.2000; RE 241.494/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti; SS 846-Agr/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e, ainda, *Inf.* 207 e 278/STF.

42 De acordo com a lei distrital: “Art. 7.º São atribuições gerais do **Técnico Penitenciário**,

além de outras decorrentes do seu exercício: **I** — exercer, operacionalizar tarefas de atendimento, serviço de vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais do Distrito Federal (...); **III** — organizar, protocolar, preparar, expedir e arquivar documentos, promover controle de pessoal, tramitar processos e expedientes dos estabelecimentos penais”.

43 Conforme se observa pela “justificação” da **PEC 111/2011**, convertida na **EC n. 74/2014**, “embora editadas a EC n. 19/98, e a n. 60/2009, estas não se revelaram suficientes para regularizar todas as situações que envolvem o pessoal contratado pelos ex-Territórios, principalmente porque os dispositivos constitucionais não fizeram referência expressa aos **servidores municipais contratados até 04 de outubro de 1988**, como também não contemplaram **aqueles que trabalharam no período de instalação dos Estados de Roraima e Amapá**”. Esse período, que compreende a criação pela Constituição Federal de 1988 até a efetiva instalação do Estado, foi definido pelo STF como sendo de **5 anos** a contar da promulgação da CF/88. Vejamos: “Servidores públicos do extinto Território Federal do Amapá: reclamação trabalhista: ilegitimidade passiva do Estado do Amapá: responsabilidade total da União pelos encargos financeiros decorrentes das despesas de pessoal do novo Estado federado **até o final dos cinco anos de sua instalação** (CF, art. 235, IX e ADCT, art. 14, § 2.º)” (**RE 396.547**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 08.03.2005, 1.ª T., *DJ* de 1.º.04.2005).

44 **Art. 149 do CPM**: “Reunirem-se militares ou assemelhados: I — agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la; II — recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência; III — assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior; IV — ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar” (**motim**).

45 **Art. 187 do CPM**: “Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias” (**deserção**).

46 **Art. 301 do CPM**: “Desobedecer a ordem legal de autoridade militar” (**desobediência**).

47 Nesse sentido, cf. **ADI 2.364-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 1.º.02.2001, *DJ*

de 14.12.2001 (mérito pendente) e, confirmando a liminar deferida em 30.05.96 (**depois de 18 anos!**), o julgamento de mérito da **ADI 1.440**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.10.2014, Pleno, *DJE* de 06.11.2014.

48 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 9. ed., p. 653.

49 De acordo com o art. 1.º da Res. n. 296/CONTRAN (que revogou a Res. n. 106/CONTRAN, considerada esta de n. 106 na justificativa de apresentação da PEC), “integram o SNT (*Sistema Nacional de Trânsito*) os órgãos e entidades **municipais** executivos de trânsito e rodoviário que disponham de estrutura organizacional e capacidade instalada para o exercício das atividades e competências legais que lhe são próprias, sendo estas no mínimo as de: engenharia de tráfego; fiscalização e operação de trânsito; educação de trânsito; coleta, controle e análise estatística de trânsito, e disponha de Junta Administrativa de Recursos de Infrações — JARI”.

50 Confira: <<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/64/255>>.

51 **Art. 7.º da Lei n. 9.503/97**: “Compõem o **Sistema Nacional de Trânsito** os seguintes órgãos e **entidades**: I — o Conselho Nacional de Trânsito — CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; II — os Conselhos Estaduais de Trânsito — CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal — CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; III — os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; IV — os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; V — a Polícia Rodoviária Federal; VI — as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e VII — as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações — JARI”.

52 Julyver Modesto de Araujo, *Emenda constitucional dos agentes de trânsito*, in: <<http://www.ctbdigital.com.br>>, comentários ao art. 7.º, acesso em 10.01.2015.

53 Idem.

54 A **Lei n. 8.745/93** dispõe sobre a **contratação, por tempo determinado**, para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. O STF tem feito interpretação bastante **restritiva** para a contratação temporária, prestigiando, naturalmente, a regra do concurso público. Como bem delimitado pela Corte, para que se considere válida a contratação por tempo determinado (temporária) é preciso que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.04.2014, Plenário, DJE de 31.10.2014, com repercussão geral. Cf., ainda: ADI 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 09.06.2004, Plenário e ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.08.2009, Plenário).

55 Nesse sentido, destacamos importantes argumentos trazidos por Julyver Modesto de Araujo, pedindo desculpas pela longa, mas importante, transcrição: “não haverá qualquer mudança, concernente às competências das Polícias Militares, que são igualmente responsáveis pela segurança pública, nos Estados e Distrito Federal, com a missão constitucional de **polícia ostensiva e preservação da ordem pública** (art. 144, § 5.º, da CF). O fato de se reconhecer a carreira dos agentes de trânsito, nos Estados e nos Municípios (e acrescentaríamos, no âmbito do DF), **não invalidará a atuação das Polícias Militares, na fiscalização de trânsito**, que continua sendo concomitante ao trabalho dos agentes de trânsito próprios de cada órgão ou entidade executivo de trânsito e rodoviário, nos termos de convênio firmado, como estabelece o **art. 23, III, do CTB**. Importante destacar que a atividade de **policimento ostensivo de trânsito** continua sendo de **exclusividade** das **Polícias Militares**, como conceitua o Anexo I do CTB: *‘função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes’* e de acordo com o art. 2.º, item 27, do Decreto federal n. 88.777/83 (R-200) — Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, que assim dispõe: *‘**Policimento Ostensivo** — Ação policial, exclusiva das Polícias Militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública... São tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, os seguintes: — ostensivo geral, urbano e rural; — **de trânsito**...’*. É fato que, embora a nomenclatura ‘policimento ostensivo de trânsito’ seja utilizada pela legislação infraconstitucional mencionada, como indicativo da função exercida pelas Polícias Militares, a inclusão do § 10 no artigo 144 passou a reconhecer a incidência do trabalho dos agentes de trânsito (estaduais e municipais) no campo da segurança pública, especificamente para **garantir o**

direito ao trânsito seguro; isto significa que a PM continua exercendo a prevenção criminal, por meio da sua ostensividade, e a repressão imediata dos crimes constatados (inclusive para os delitos ocorridos na utilização da via pública); por outro lado, não caberá aos agentes de trânsito invadirem a competência constitucional das Polícias Militares, não lhes cabendo ações próprias de polícia, como a busca pessoal ou veicular, à procura de armas e drogas (a qual tem como base o Código de Processo Penal, em seu art. 244, quando fundada suspeita), ou a ‘perseguição’ ou prisão a criminosos (ressalvada a possibilidade de qualquer um do povo prender quem esteja em situação de flagrante delito, nos termos do artigo 301 do CPP)” (idem).

- 1 O relator, Ministro Sydney Sanches — medida cautelar, *RTJ* 150/68 —, no julgamento da **ADI 939-7/DF**, entendeu tratar-se de cláusula pétrea a garantia constitucional prevista no art. 150, III, “b”, declarando que a EC n. 3/93, ao pretender subtraí-la da esfera protetiva dos destinatários da norma, estaria ferindo o limite material previsto no art. 60, § 4.º, IV, da CF/88.
- 2 P. Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 25. ed., p. 563-564 — original sem grifos.
- 3 I. W. Sarlet, *A eficácia dos direitos fundamentais*, 10. ed., p. 46.
- 4 D. Dimoulis, L. Martins, *Teoria geral dos direitos fundamentais*, p. 35.
- 5 P. Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 25. ed., p. 564.
- 6 Norberto Bobbio, em sua obra *A era dos direitos*, na nota 9 da parte introdutória, elenca preciosa literatura sobre os direitos humanos de terceira geração, enquanto “novos direitos”.
- 7 P. Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 25. ed., p. 569.
- 8 *A era dos direitos*, p. 6.
- 9 I. W. Sarlet, *A eficácia dos direitos fundamentais*, 10. ed., p. 51.
- 10 P. Bonavides, *Curso de direito constitucional*, 25. ed., p. 593.
- 11 Rui Barbosa, *República: teoria e prática* (textos doutrinários sobre direitos humanos e políticos consagrados na primeira Constituição da República. Seleção e coordenação de Hilton Rocha), Petrópolis: Vozes, apud José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 360.
- 12 *Curso de direito constitucional*, p. 67-71, passim.
- 13 *Curso de direito constitucional*, p. 282.
- 14 *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 185.
- 15 *Comentário contextual à Constituição*, p. 408.
- 16 *Comentário contextual à Constituição*, p. 408.
- 17 *Comentário contextual à Constituição*, p. 409.
- 18 Sobre o tema, cf. Daniel Sarmento, *Direitos fundamentais e relações privadas*, 2. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; Luis Virgílio Afonso da Silva, *A constitucionalização*

do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2005; Ingo Wolfgang Sarlet, *A eficácia dos direitos fundamentais*, 7. ed., Porto Alegre: Livr. do Advogado Ed., 2007; Thiago Sombra, *A eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas*: a identificação do contrato como ponto de encontro dos direitos fundamentais, Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2004; Andrey Borges de Mendonça e Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira, *Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas*: leituras complementares de constitucional — direitos fundamentais, Marcelo Novelino Camargo (org.), Salvador: Jus Podivm, 2006; Jane Reis Gonçalves Pereira, *Interpretação constitucional e direitos fundamentais*, Rio de Janeiro: Renovar, 2006; Ana Paula de Barcellos, *Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional*, Rio de Janeiro: Renovar, 2005; Gustavo Tepedino, *Temas de direito civil*, 4. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, t. I, passim, e outros.

19 Propondo um modelo mais flexível, buscando romper a dicotomia entre a eficácia direta e a indireta, **conciliando** as citadas construções teóricas, indicamos a leitura da tese de livre-docência de Virgílio Afonso da Silva, defendida no ano de 2004 na USP (cf. *A constitucionalização do direito*, cit., especialmente o seu cap. 7).

20 Assim, indispensável a leitura do referido voto, que pode ser encontrado em **Inf. 405/STF**.

21 Sobre a ponderação de interesses, cf. Daniel Sarmento, *A ponderação de interesses na Constituição Federal*, passim.

22 D. Dimoulis, L. Martins, *Teoria geral dos direitos fundamentais*, p. 76-80.

23 D. Dimoulis, L. Martins, *Teoria geral dos direitos fundamentais*, p. 79.

24 J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 7. ed., p. 81. Cf., ainda, J. H. Meirelles Teixeira, *Curso de direito constitucional*, 1991, p. 213.

25 De acordo com o item 2, desse art. 6.º, da parte III, **nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida**, esta poderá ser imposta **apenas** nos casos de **crimes mais graves**, em conformidade com legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do Pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma **sentença transitada em julgado** e proferida por **tribunal competente**. Conforme anota Fábio Konder Comparato, a admissão da pena de morte representa um **compromisso provisório** entre os Estados que ainda a

mantêm e os que já a aboliram, “resquício de um passado em que a punição criminal exercia unicamente uma função retributiva, segundo a exata correspondência entre crime e castigo, própria da lei de talião” (*A afirmação histórica dos direitos humanos*, 7. ed., p. 309). Lembramos, conforme se observa neste tópico, que o *Segundo Protocolo Facultativo do Pacto Internacional* objetivou a **abolição** da pena capital.

26 Não é admitida qualquer reserva ao referido Protocolo, exceto a formulada no momento da ratificação ou adesão que preveja a aplicação da **pena de morte em tempo de guerra** em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema, cometida durante referido período de crise (art. 2.º, 1).

27 Cf. P. Häberle, *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição*, 1997, passim.

28 Conforme bem colocou o Min. Marco Aurélio em seu voto, no julgamento da ADPF 54, diante de risco de referência às nefastas práticas nazistas, “apesar de alguns autores utilizarem expressões ‘aborto eugênico ou eugenésico’ ou ‘antecipação eugênica da gestação’, **afasto-as**, considerado o indiscutível viés ideológico e político impregnado na palavra eugenia”.

29 Para aprofundamento, cf. Daniel Sarmiento e Flávia Piovesan (org.), *Nos limites da vida*, Lumen Juris, 2007, passim.

30 Nesse sentido, a **S. 683/STF**: “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. No mesmo sentido, o art. 27, *caput*, da Lei n. 10.741/2003 (**Estatuto do Idoso**), nos seguintes termos: “na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir”. Sobre o Estatuto, cf. interessante e muito didática obra de Luiz Eduardo Alves de Siqueira, *Estatuto do idoso de A a Z*, passim. Ainda, lembrar que alguns dispositivos estão sendo questionados no STF (arts. 39 e 94 do Estatuto), nos termos da ADI 3.096/DF, 19.12.2003. O Prof. Damásio, em interessante estudo, entende que a legislação criminal brasileira considera **idoso** a pessoa de idade *igual ou superior a 60 anos* (cf. Damásio de Jesus, *Conceito de idoso na legislação penal brasileira*, São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, mar. 2004 — disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/artigos/art_183.htm>).

- 31 Celso Antônio Bandeira de Mello, *Conteúdo jurídico do princípio da igualdade*, p. 21, e desenvolvimento, p. 23-43.
- 32 Cf. interessante trabalho de Paulo Lucena de Menezes, *A ação afirmativa* (affirmative action) *no direito norte-americano*, passim, esp. p. 147-154 para o ordenamento brasileiro, e, também, o do Ministro do STF Joaquim Barbosa, intitulado *Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento de transformação social — a experiência dos EUA*, passim.
- 33 *Curso de direito constitucional*, 6. ed., 2002, p. 93 (original sem grifos).
- 34 José Celso de Mello Filho, *Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República)*, 4. ed., 2014, p. 23 (<<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=publicacaoPublicacaoInstitucionalCuriosidade>>). Lembramos um fato insólito: com a indicação da primeira mulher ao cargo de Ministro do STF, a Corte teve que passar por uma reforma para construir um **banheiro feminino** ao lado do plenário!
- 35 *Notícias STF*, 07.04.2003 — 16h59: “Lula pretende indicar negro para o Supremo, diz secretária ao presidente do STF” (<www.stf.gov.br>).
- 36 Na linha do julgado na ADI 3.324, fortalecendo o **princípio da congeneridade**, cf. Rcl 4.036-MC/RJ, j. 16.05.2006, *DJ* de 22.05.2006, p. 25.
- 37 Ingo Sarlet, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 452 e 454.
- 38 Daniel Sarmento, A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”, in: *Livres e iguais: estudos de direito constitucional*, p. 208.
- 39 Conforme estabeleceu Barroso, “... as liberdades de informação e de expressão servem de fundamento para o exercício de outras liberdades, o que justifica uma **posição de preferência** — *preferred position* — em relação aos direitos fundamentais individualmente considerados. Tal posição, consagrada originariamente pela Suprema Corte americana, tem sido reconhecida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol e pela do Tribunal Constitucional Federal alemão. Dela deve resultar a **absoluta excepcionalidade da proibição prévia de publicações**, reservando-se essa medida aos raros casos em que não seja possível a composição posterior do dano que eventualmente seja causado aos direitos da personalidade. A opção pela composição posterior tem a inegável vantagem de não sacrificar totalmente nenhum dos valores envolvidos, realizando a ideia de **ponderação**” (Luís Roberto Barroso, *Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação*

Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. In: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art_03-10-01.htm##LS>, acesso em 1.º.01.2015). (Cf., ainda, do mesmo autor, *Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação*. In: *Temas de direito constitucional*, t. III, p. 79-130, esp. 105-106).

40 Daniel Sarmiento, op. cit., p. 262.

41 Op. cit., p. 262.

42 Op. cit., p. 257.

43 Daniel Sarmiento, comentário ao art. 5.º, IV, in: J. J. Gomes Canotilho, Gilmar F. Mendes, Ingo W. Salet e Lenio L. Streck, *Comentários à Constituição do Brasil*, p. 257.

44 Idem.

45 Ingo W. Sarlet, *Curso de direito constitucional*, 2. ed., p. 470.

46 **Art. 19, caput, da Lei n. 12.965/2014**: “Com o intuito de **assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura**, o provedor de aplicações de *internet* somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, **após ordem judicial específica**, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.

47 **Art. 21, caput, da Lei n. 12.965/2014**: “O provedor de aplicações de *internet* que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo **cenas de nudez** ou de **atos sexuais de caráter privado** quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo”.

48 Virgílio Afonso da Silva, *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*, p. 167-170.

49 No mesmo sentido: **HC 95.244**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.03.2010, Primeira Turma, *DJE* de 30.04.2010; **HC 84.827**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.08.2007, Primeira Turma, *DJ* de 23.11.2007.

50 O **Decreto n. 5.687/2006** promulga a *Convenção das Nações Unidas contra a*

Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31.10.2003 e assinada pelo Brasil em 09.12.2003, tendo sido o seu texto aprovado pelo Congresso Nacional por meio do **Decreto Legislativo n. 348/2005**.

51 Art. 286 do CP. Incitação ao crime: “Incitar, publicamente, a prática de crime”.

52 Art. 287 do CP. Apologia de crime ou criminoso: “fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime”.

53 Art. 33, § 2.º, da Lei n. 11.343/2006: “induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga”.

54 Em momento posterior, cabe lembrar que a **EC n. 19/2000** à Constituição do Acre **acrescentou**, independentemente da decisão da Corte, a **expressão *sob a proteção de Deus***.

55 José Afonso da Silva. *Comentário contextual à Constituição*, 5. ed., p. 94.

56 A 19.^a edição deste trabalho foi fechada em 20.06.2015; assim, o meu ilustre leitor poderá acompanhar o julgamento pelo site do CNJ (<<http://www.cnj.jus.br>>), ou, se preferir, encaminhando um e-mail para pedrolenza@terra.com.br (matéria pendente).

57 “(...). Em mero juízo de delibação, pode-se afirmar que a designação de data alternativa para a realização dos exames não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, convolvendo-se em privilégio para um determinado grupo religioso. Decisão da Presidência, proferida em sede de contracautela, sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de acarretar à ordem pública. Pendência de julgamento da (...) ADI 3.714, nas quais esta Corte poderá analisar o tema com maior profundidade” (**STA 389-AgR**, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. 03.12.2009, Plenário, *DJE* de 14.05.2010).

58 Autos de primeira instância n. 0019890-16.2012.4.03.6100 — sentença proferida em 22.05.2013, tendo o recurso dado entrada no TRF3 em 06.09.2013 — *pendente*.

59 Frise-se: **ordem judicial**, não cabendo determinação de autoridade administrativa, ou policial.

60 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, p. 72.

61 “Crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição. Interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar. Nulidade. Não ocorrência. Medida executada nos termos da Lei 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e deferimento pelo juízo competente). **Excepcionalidade do caso:** suspeita de envolvimento de autoridades policiais da

delegacia local” ([HC 96.986](#), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.05.2012, 2.^a T., *DJE* de 14.09.2012).

62 “Transparência — Em sessão administrativa realizada no dia 22 de maio de 2012, os ministros do STF decidiram divulgar na *internet* a remuneração paga a ministros e servidores da Corte. A decisão atendeu ao comando da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), que entrou em vigor em 16 de maio de 2012” (*Notícias STF*, 04.01.2013). Analisando a matéria, “o Tribunal, apreciando o *tema 483 da repercussão geral*, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento a recurso extraordinário, fixando-se a tese de que é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”. A privacidade ficaria mitigada por se tratar de agente público, visando à eficiência (cf. [ARE 652.777](#), j. 23.04.2015).

63 O *leading case* foi o RE 153.771-MG, Rel. Min. Moreira Alves, 20.11.1996, *DJ* de 05.09.1997 e *Inf. STF 54/96*: “EMENTA: IPTU. Progressividade. No sistema tributário nacional é o IPTU inequivocamente um imposto real. Sob o império da atual Constituição, não é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu artigo 145, § 1.º, porque esse imposto tem caráter real que é incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse dispositivo constitucional (genérico) com o artigo 156, § 1.º (específico). A interpretação sistemática da Constituição conduz inequivocamente à conclusão de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que alude o inciso II do § 4.º do artigo 182 é a explicitação especificada, inclusive com limitação temporal, do IPTU com finalidade extrafiscal aludido no artigo 156, I, § 1.º. Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1.º, aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2.º e 4.º do artigo 182, ambos da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se inconstitucional o subitem 2.2.3 do setor II da Tabela III da Lei 5.641, de 22.12.89, no município de Belo Horizonte”. Na doutrina, o ilustríssimo [Carrazza](#) já defendia, mesmo antes da EC n. 29/2000, a progressividade do IPTU (cf. *Curso de direito constitucional tributário*, 16. ed., p. 90-98).

64 *Curso de direito civil*, 2002, v. 6, p. 36.

65 José Celso de Mello Filho, *Constituição Federal anotada*, p. 374, comentários ao art. 153, § 33.

66 *Vide* Lei n. 9.279/96 (propriedade industrial) e Lei n. 9.610, de 19.02.1998 (direitos autorais).

67 Nesse sentido, cf. os arts. 52.º, 3, “a”; 60.º; 81.º, “i”, e 99.º, “e”, da **Constituição da República Portuguesa de 02.04.1976** (revista pelas Leis Constitucionais ns. 1/82, 1/89, 1/92, 1/97, 1/01 e 1/04). A íntegra da Constituição portuguesa pode ser consultada no site <<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html>>.

68 Esse direito fundamental dos consumidores foi regulamentado nos termos da **Lei n. 12.741/2012**. De acordo com o seu art. 1.º, emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo o território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.

69 *Curso de direito constitucional positivo*, 23. ed., 2004, p. 262.

70 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 261-262.

71 *Leis civis comentadas*, p. 181, comentários ao art. 1.º do CDC. **Cuidado**: àqueles que estudam para provas que exigem o conhecimento das regras específicas do CDC, como é o concurso para a Procuradoria da República, indispensável a leitura minuciosa da lei, assim como dos livros específicos sobre o assunto. Nesse sentido, cf. o programa para provimento de cargos de Procurador da República aprovado pela Res. CSMPF n. 93, de 04.09.2007, no qual o grupo II trata da matéria de “direito do consumidor”.

72 *Curso de direito constitucional positivo*, 23. ed., p. 441.

73 Nesse sentido, confira Pedro Lenza, *Teoria geral da ação civil pública*, p. 133-134.

74 K. Watanabe, Acesso à justiça e sociedade moderna, in A. P. Grinover (coord.), *Participação e processo*, p. 128. Em estudo anterior Watanabe já havia sacramentado a expressão **ordem jurídica justa** (K. Watanabe, Assistência judiciária e o juizado de pequenas causas, in Kazuo Watanabe [et al.], *Juizado Especial de Pequenas Causas*: Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984, p. 161).

75 Interessante a **S. 667/STF, 24.09.2003**: “viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa”.

76 Mauro Cappelletti, Bryant Garth, *Acesso à justiça*, p. 31.

77 Nelson Nery Junior, *Princípios do processo civil na Constituição Federal*, p. 92.

78 “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde que não exigida garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o pedido” (art. 153, § 4.º, da CF/69).

79 “O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, reguladas em lei. A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.” Findo tal prazo, perfeitamente possível o ingresso no judiciário, mesmo sem decisão final.

80 Nelson Nery Junior, *Princípios do processo civil na Constituição Federal*, p. 80.

81 “O respeito ao direito adquirido, com a consequente proibição da retroatividade da norma legal, é um verdadeiro instrumento de **paz social, impeditivo do arbítrio e do abuso de poder por parte do detentor deste**” (Carlyle Popp, A retroatividade das normas constitucionais e os efeitos da Constituição Federal sobre os direitos adquiridos. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 29, n. 113, p. 88, jan./mar. 1992).

82 “Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título” (art. 17, *caput*, do ADCT). Assim, entendemos que a **Reforma da Previdência** feriu o direito adquirido ao estabelecer contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas e ao mudar as regras de transição de aposentadoria dos ocupantes de cargos efetivos que entraram no serviço público até 16.12.1998. No entanto, o STF, por 7 votos a 4, considerou constitucional a cobrança de inativos e pensionistas instituída no art. 4.º da EC n. 41/2003, mas desde que incidente somente sobre a parcela dos proventos e pensões que exceder o teto estabelecido no art. 5.º da EC n. 41/2003 (cf. *Inf. 357/STF*).

83 A LC n. 110/2001, em seu art. 4.º, autoriza, em caso de adesão facultativa do trabalhador ao termo de adesão (acordo) firmado com a CEF, o crédito, nas contas vinculadas do FGTS, do percentual de **16,64%** equivalente ao período de 1.º.12.1988 a 28.02.1989 e do percentual de 44,80% equivalente ao mês de abril/1990. De modo geral, contudo, há várias decisões judiciais que fixaram para janeiro/1989 o percentual de **42,72%**. Assim, o objetivo dos trabalhadores era conseguir a diferença entre o percentual do acordo (administrativo) e o que vem sendo fixado por quem fez a opção pela via judicial (cf.

Enunciado n. 21 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais). Entretanto, como visto, sem a análise do caso concreto, não se pode simplesmente desconsiderar o acordo, sob pena de violar, entre outros, o princípio do **ato jurídico perfeito**. Sobre o assunto, *vide Inf. 381/STF*.

84 L. A. D. Araujo e V. Serrano Nunes Júnior, *Curso de direito constitucional*, 2002, p. 141.

85 Nelson Nery Junior, *Princípios do processo civil na Constituição Federal*, 7. ed., p. 66-67.

86 Nelson Nery Junior, *Princípios do processo civil na Constituição Federal*, p. 61.

87 Conforme lembra Alexandre de Moraes, em audiência com o Ministro Marco Aurélio do STF, “... há uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos entendendo a medida como inconstitucional quando foi adotada pelo governo do Peru. E a ideia não é possível porque não identifica a pessoa ou o órgão julgador”. Renato Nalini, presente à referida audiência, também se mostrou contra a técnica do “juiz sem rosto”. “A ideia, segundo Nalini, não é compatível com nada do que o direito brasileiro produziu até o momento. ‘Temos é que equipar o Estado e tranquilizar o juiz para que ele continue a decidir de acordo com a Lei, a Constituição e a sua consciência’” (*Notícias STF*, 19.03.2003, in <www.stf.gov.br>).

88 Luiz Flávio Gomes, Está nascendo o primeiro Tribunal Penal Internacional, *Jus Navigandi*, Teresina, ano 6, n. 56, abr. 2002, disponível em: <<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2920>>, acesso em: 2 fev. 2005. Para uma profunda crítica, inclusive em relação à inconstitucionalidade da EC n. 45/2004 nesse ponto, cf.: Dimitri Dimoulis, O art. 5.º, § 4.º, da Constituição Federal: dois retrocessos políticos e um fracasso normativo, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 107.

89 Cf. o site do “TPI”: <www.icc-cpi.int>.

90 Pelo afastamento da prisão perpétua, cf. Fábio Ramazzini Bechara, *Tribunal Penal Internacional e o princípio da complementaridade*, São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, dez. 2003, disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>. Sobre a relativa aceitação de outros tribunais internacionais (que não de natureza criminal), na medida em que, pela **EC n. 45/2004**, haveria “... a presunção de que a submissão à jurisdição a qualquer Corte judiciária internacional tenha que necessariamente decorrer de disposição da

Constituição...”, como expresso no art. 5.º, § 4.º, cf. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, *Tratados internacionais na Emenda Constitucional n. 45*, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 83.

91 Leia a interessante íntegra do voto do Min. Celso de Mello em *Notícias STF*, 30.07.2009.

92 *Boletim dos Procuradores da República*, n. 14, jun. 1999, in <www.anpr.org.br/boletim/boletim14/reforma.htm>.

93 Trata-se de proposta original do Executivo que, como se sabe, foi modificada por meio do Substitutivo do Deputado Aloysio Nunes, que deu a redação final que ora se critica. O texto modificado acrescentava dois incisos ao art. 109, nos seguintes termos: “Art. 109. (...) XII — os crimes praticados em detrimento de bens ou interesses sob a tutela de órgão federal de proteção dos direitos humanos; XIII — as causas civis ou criminais nas quais órgão federal de proteção dos direitos humanos ou o Procurador-Geral da República manifeste interesse”.

94 *Boletim dos Procuradores da República*, n. 14, jun. 1999, in <www.anpr.org.br/boletim/boletim14/reforma.htm>.

95 Pelo Decreto n. 678/92, foi promulgada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (*Pacto de São José da Costa Rica*), de 22 de novembro de 1969. O Congresso Nacional, por seu turno, aprovou, pelo Decreto-lei n. 89/98, solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção, de acordo com o previsto no art. 62 daquele instrumento. A Declaração de aceitação da competência obrigatória da *Corte Interamericana de Derechos Humanos* foi depositada junto à Secretaria-Geral da OEA em 10 de dezembro de 1998. Por tudo isso, o Decreto presidencial n. 4.463/2002, nos termos de seu art. 1.º, reconheceu como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, **a competência da Corte Interamericana de Derechos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Derechos Humanos** (*Pacto de São José da Costa Rica*), sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998.

96 Flávia Piovesan, *Reforma do Judiciário e direitos humanos*, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 67.

97 Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, *Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988*, p. 305.

- 98 Nesse sentido, cf. **Rcl 15.626**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.09.2014, *DJE* de 19.09.2014.
- 99 No mesmo sentido: **HC 102.199**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.08.2010, 2.^a T, *DJE* de 24.09.2010; **HC 96.818**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.08.2010, 2.^a Turma, *DJE* de 17.09.2010; **HC 102.355**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 04.05.2010, 1.^a Turma, *DJE* de 28.05.2010.
- 100 Cf., no *item 21.4.2*, aprofundamento destacando o entendimento do STF no sentido de ter o novo ordenamento recepcionado a *Lei n. 6.683/79*, a chamada “**Lei de Anistia**” (ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau, j. 29.04.2010, Plenário, *DJE* de 06.08.2010).
- 101 Fábio Ramazzini Bechara e Pedro Franco de Campos, *Princípios constitucionais do processo penal: questões polêmicas*, São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, jan. 2005 — disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
- 102 *Princípios constitucionais...*, cit.
- 103 Damásio E. de Jesus, *Código de Processo Penal anotado*, p. 10, comentário ao art. 6.º, VIII.
- 104 Fábio Ramazzini Bechara, Pedro Franco de Campos, *Princípios constitucionais...*, cit.
- 105 Fábio Ramazzini Bechara, Pedro Franco de Campos, *Princípios constitucionais...*, cit.
- 106 Nesse sentido, cf. **HC 115.539**, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03.09.2013, Plenário, *DJe* de 17.09.2013.
- 107 O devido processo legal substantivo e o Supremo Tribunal Federal nos 15 anos da Constituição Federal, in André Ramos Tavares, Olavo A. V. Alves Ferreira, Pedro Lenza (coord.), in *Constituição Federal: 15 anos: mutação e evolução, comentários e perspectivas*, p. 103. Na jurisprudência do STF, cf. RE 197.917/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, *Inf. 341/STF*.
- 108 Cf. *item 3.6.8* desse nosso estudo e art. 156, I, do *Código de Processo Penal*, introduzido pela Lei n. 11.690/2008.
- 109 Mirabete divide as provas em: a) **provas ilícitas**: “... as que contrariam as normas de Direito Material, quer quanto ao meio ou quanto ao modo de obtenção”; b) **provas ilegítimas**: “... as que afrontam normas de Direito Processual, tanto na produção quanto na introdução da prova no processo”. E conclui pela total inadmissibilidade, tanto no processo penal como no civil, das provas ilícitas e ilegítimas (*Processo penal*, p. 252).

110 *Direito constitucional*, p. 116.

111 A. C. de A. Cintra, A. P. Grinover e C. R. Dinamarco, *Teoria geral do processo*, 12. ed., p. 69. Nesse sentido, ainda, J. C. Barbosa Moreira, A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito, in *Temas de direito processual — 2.ª série*, p. 86 e s., e M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, p. 405 e s.

112 Lenio Luiz Streck, Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?, *Revista Consultor Jurídico*, 18.12.2014, p. 6.

113 **Art. 489, § 1.º, CPC/2015**: “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I — se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II — empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III — invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV — não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V — se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI — deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

114 Marcus Vinícius Rios Gonçalves, *Direito processual civil esquematizado*, 5. ed., p. 65.

115 “Art. 49. Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: I — no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II — recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento das partes. Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de 10 (dez) dias.”

116 Dispõe de forma idêntica ao art. 49 da LC n. 35/79, acima citado. No CPC/2015, a regra está contida no art. 143.

117 “Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1.º Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2.º A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou

falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.”

118 “... o texto constitucional é linear, não condicionado, ao contrário do § 2.º do artigo 630 do Código de Processo Penal. De qualquer maneira, é possível excluir-se a verba *quando o dano decorre de ato do próprio réu da ação penal*, surgindo apenas o conflito da alínea ‘b’ do § 2.º do artigo 630 com os novos ares constitucionais...” (j. 25.05.2004, Rel. Min. Marco Aurélio — AI 462.831/RJ).

119 Cf. Damásio E. de Jesus, *Código de Processo Penal anotado*, 18. ed., p. 487, comentários ao art. 630 do CPP. Sobre a responsabilidade do Estado no caso de **erro judiciário**, cf. interessante acórdão do STJ: “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Responsabilidade objetiva. Prisão ilegal. Danos morais. 1. O Estado está obrigado a indenizar o particular quando, por atuação dos seus agentes, pratica contra o mesmo **prisão ilegal**. 2. Em caso de prisão indevida, o fundamento indenizatório da responsabilidade do Estado deve ser focado sobre o prisma de que a entidade estatal assume o dever de respeitar, integralmente, os direitos subjetivos constitucionais assegurados ao cidadão, especialmente, o de ir e vir. 3. O Estado, ao prender indevidamente o indivíduo, atenta contra os direitos humanos e provoca dano moral ao paciente, com reflexos em suas atividades profissionais e sociais. 4. A indenização por danos morais é uma recompensa pelo sofrimento vivenciado pelo cidadão, ao ver, publicamente, a sua honra atingida e o seu direito de locomoção sacrificado. **5. A responsabilidade pública por prisão indevida, no direito brasileiro, está fundamentada na expressão contida no art. 5.º, LXXV, da CF.** 6. Recurso especial provido” (REsp 220.982/RS (1999/0057692-6), DJ de 03.04.2000, p. 116, Rel. Min. José Delgado, data da decisão: 22.02.2000, 1.ª Turma).

120 *Código de Processo Civil comentado*, p. 83.

121 **Cuidado:** esse tema deve ser acompanhado por aqueles que prestam concursos para o exercício da atividade notarial e de registro! “Atividade notarial. Natureza. Lei n. 9.534/97. Registros públicos. Atos relacionados ao exercício da cidadania. Gratuidade. Princípio da proporcionalidade. Violação não observada. Precedentes. Improcedência da ação. A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. Não ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os ‘reconhecidamente pobres’ do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva” (**ADI 1.800**, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo

Lewandowski, j. 11.06.2007, *DJ* de 28.09.2007). Em igual sentido, na linha da constitucionalidade, a **ADC 5**, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.06.2007, *DJ* de 05.10.2007.

122 Pedro Lenza, *Teoria geral da ação civil pública*, p. 318.

123 J. R. dos S. Bedaque, *Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência* (tentativa de sistematização), p. 15. Conforme observa em seguida o ilustre professor, “o simples fato de o direito permanecer insatisfeito durante todo o tempo necessário ao desenvolvimento do processo cognitivo já configura dano ao seu titular. Além disso, acontecimentos podem também se verificar nesse ínterim, colocando em perigo a efetividade da tutela jurisdicional. Esse quadro representa aquilo que a doutrina identifica como o *dano marginal*, causado ao agravado pela duração do processo”. E completa: “... com o objetivo de evitar o dano marginal causado pelo processo, existe a possibilidade de sumarização da atividade cognitiva, tornando admissível a tutela jurisdicional mediante conhecimento não exauriente” (p. 19-20).

124 A Deputada Zulaiê Cobra, em seu relatório à **PEC n. 96-A/92** (Reforma do Judiciário), destacou: “também procurando combater a morosidade da Justiça, introduzimos, como princípio de ordem processual, o direito à razoável duração do processo, fazendo aditar inciso ao art. 5.º da Constituição Federal. Trata-se de direito consagrado pelas Constituições de Portugal (art. 20, n. 4) e do México (art. 17), tendo a AMB e a OAB sugerido sua adoção” (in Petrônio Calmon Filho (org.), *Reforma constitucional do Poder Judiciário*, p. 70).

125 Adotada, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, em 22.11.1969. Entrou em vigor, internacionalmente, em 18.07.1978 (art. 74, § 2.º), tendo o Governo brasileiro depositado a **carta de adesão** à Convenção em 25.09.1992, e o Decreto federal n. 678, de 06.11.1992, *DOU* de 09.11.1992, p. 15562, determinou o seu cumprimento no País. Nesse particular, a partir da **Reforma do Judiciário** (*EC n. 45/2004*), os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ganham maior relevância, já que, desde que aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, terão *status* de norma constitucional.

126 Ada Pellegrini Grinover, A necessária reforma infraconstitucional, in André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesús Lora Alarcón (coord.), *Reforma do Judiciário*, p. 501.

127 A íntegra desses compromissos pode ser consultada em *Notícias STF*, 15.12.2004 — 20h40.

128 O **II Pacto Republicano** pode ser acessado em *Notícias STF*, 13.04.2009 — 18h.

129 Confira o texto apresentado em: <<http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/88428.pdf>>.

130 Com atraso de 8 anos, mas seguindo o mesmo contexto da *Reforma do Poder Judiciário*, a **EC n. 69/2012** alterou os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a **Defensoria Pública do Distrito Federal**, havendo, dessa forma, o seu inegável fortalecimento. Por sua vez, com atraso de 9 anos, a **EC n. 74/2013** assegurou a autonomia da **Defensoria Pública da União**, reforçando-a na linha do estabelecido para a Defensoria Pública do DF (art. 134, § 3.º, CF/88). Finalmente, a **EC n. 80/2014**, de maneira impressionante e histórica, aloca a defensoria pública em seção própria do Capítulo IV, do Título IV, da Constituição, desvinculando-a da seção que trata da advocacia privada. Remetemos o leitor para o *item 12.6*, onde estudamos com maior detença o assunto.

131 Para acompanhamento das propostas legislativas, cf. a *Enciclopédia Eletrônica* mantida pelo IBDP — Instituto Brasileiro de Direito Processual: <<http://www.direitoprocessual.org.br/site>>.

132 Conforme explicamos no *item 14.11.7.2*, muito embora prevista uma chamada “ação popular” no art. 157 da Constituição de 1824, em razão de naturezas jurídicas distintas, consideremos como sendo a **Constituição de 1934** a que, pela primeira vez, constitucionalizou a **ação popular**, que já era prevista na *Lei n. 4.717, de 29.06.1965*, ainda em vigor.

133 Redação determinada pela EC n. 23, de 02.09.1999.

134 Redação determinada pela EC n. 22, de 18.03.1999.

135 Redação determinada pela EC n. 23, de 02.09.1999.

136 Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.

137 José da Silva Pacheco, *Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas*, 4. ed., p. 124-148. Destaca o autor, na **Inglaterra**, “... a) o *mandamus*, para mandar a autoridade que não observou a norma obrigatória a cumpri-la; b) o *prohibition*, para obstar que a autoridade pratique uma ilegalidade ou viole uma regra de direito; c) o *certiorari*, para anular ato ilegal; d) o *quo warranto*, para conferir a legalidade da investidura em um cargo público; e e) o *habeas corpus*, para impedir a prisão ou detenção ilegal”. Nos **EUA**, além dos *writs* já citados, o *mandatory injunction* (para praticar o ato) e *prohibitory injunction* (para não praticar o ato) (op. cit., p. 131-132). No **México**, lembra que o *juicio de amparo*, no início, servia para “... conhecer reclamações contra os atos do Poder Executivo e do Legislativo... Visava, de início, ao controle da constitucionalidade das leis e atos administrativos, mas depois estendeu-se, também, ao controle da legalidade dos atos de todas as autoridades, até mesmo as judiciárias” (op. cit., p. 133-138). Cf., ainda, comparando o MS brasileiro com o *juicio de amparo*, Héctor Fix Zamudio, Alejandro Ríos Espinoza, Niceto Alcalá-Zamora, *Tres estudios sobre el mandato de seguridad brasileño*, passim.

138 Interessante notar que é no texto de 1988 que, além da exceção do “HC”, pela primeira vez se faz exceção também ao *habeas data*. O motivo é simples: o “**HD**” surge pela primeira vez, como já visto, no texto de 1988.

139 Hely Lopes Meirelles, *Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”*, p. 34-35.

140 “A atual expressão *direito líquido e certo* substitui a precedente, da legislação criadora do mandado de segurança, *direito certo e incontestável*. Nenhuma satisfaz. Ambas são impróprias e de significação equívoca (...). O direito, quando existente, é sempre líquido e certo; os fatos é que podem ser imprecisos e incertos, exigindo comprovação e esclarecimentos para propiciar a aplicação do Direito invocado pelo postulante” (H. L. Meirelles, *Mandado de segurança...*, cit., p. 34).

141 *Elementos de direito constitucional*, p. 179.

142 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, p. 157-158.

143 **Art. 267, § 4.º, CPC**: “depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

144 **Art. 269, V, CPC**: “Haverá resolução de mérito: ... V — quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação”.

145 Cf. Súmulas 629 e 630/STF: “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes” (S. 629/STF); “a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria” (S. 630/STF). Nesse sentido, o art. 21 da Lei n. 12.016/2009: “O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”.

146 “Quando a Constituição autoriza um partido político a impetrar mandado de segurança coletivo, só pode ser no sentido de defender os seus filiados e em questões políticas, ainda assim, quando autorizado por lei ou pelo estatuto. Impossibilidade de dar a um partido político legitimidade para vir a Juízo defender 50 milhões de aposentados, que não são, em sua totalidade, filiados ao partido e que não autorizaram o mesmo a impetrar mandado de segurança em nome deles” (STJ, MS 197/DF, 20.08.1990, *RSTJ*, 12/215).

147 *Elementos de direito constitucional*, p. 203.

148 Dirley da Cunha Júnior, *Controle das omissões do Poder Público*, p. 553.

149 “Por maioria de votos, o Tribunal reconheceu a legitimidade ativa de entidades sindicais para a propositura de **mandado de injunção coletivo**, quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos constitucionais de seus membros... Precedentes citados: MI 20-DF (*DJU* 22.11.96), MI 73-DF (*DJU* 19.12.94), MI 361-RJ (*RTJ* 158/375). Prosseguindo no julgamento, o Tribunal julgou prejudicado o mandado de injunção pela superveniência de medida provisória disciplinando o art. 7.º, XI, da CF, objeto da ação. Vencido, neste ponto, o Min. Sepúlveda Pertence. MI 102-PE, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão, Min. Carlos Velloso, 12.2.98” (cf. *Inf.* 99/STF). Ver, ainda, MI 342-4-SP, Rel. Min. Moreira Alves, *RT* 713/240, admitindo legitimidade dos sindicatos (art. 8.º, III). Cf., também, **MI 1.616**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.11.2009, *DJE* de 11.11.2009, por este autor impetrado em nome da classe dos *Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil — AFRFB*, autoridades fazendárias, fiscais e aduaneiras.

150 Em igual sentido, cf. **MI 758**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.º.07.2008, *DJE* de

26.09.2008. Cf., também, **MI 1.616**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.11.2009, *DJE* de 11.11.2009, por este autor impetrado em nome da classe dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil — AFRFB, autoridades fazendárias, fiscais e aduaneiras (**MI Coletivo**). Em relação ao **tema da aposentadoria especial do servidor público**, após **reiteradas decisões** sobre essa matéria constitucional (cf., por exemplo, MI 721, MI 795, MI 788, MI 925, MI 1.328, MI 1.527, MI 2.120, MI 1.785, MI 4.158 AgR-segundo, MI 1.596 AgR, MI 3.215 AgR-segundo), o **STF** aprovou a *PSV 45* e, assim, editou, em 09.04.2014, a **SV 33**, com o seguinte teor: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4.º, inciso III da Constituição Federal, **até a edição de lei complementar específica**” (*DJE* de 24.04.2014).

151 O aviso prévio (art. 7.º, XXI, da CF/88), de acordo com a nova regra trazida pela **Lei n. 12.506/2011**, será concedido na proporção de **30 dias** aos empregados que contem até **1 ano** de serviço na **mesma** empresa, sendo acrescidos **3 dias** por **ano** de serviço prestado na **mesma** empresa, até o **máximo de 60 dias**, perfazendo um total de até **90 dias** (quando, para essa hipótese, terá o empregado que ter trabalhado, na **mesma** empresa, por 21 anos!).

152 Houve autorização para que os Ministros do STF apliquem monocraticamente esse entendimento aos mandados de injunção **pendentes** de julgamento, desde que impetrados **antes** do advento da lei regulamentadora (**MI 1.090**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.02.2013, Plenário, *DJE* de 23.04.2013). Contudo, nos termos do voto do Relator, entendeu a Corte **não ser possível**, por **segurança jurídica**, “exigir-se a aplicação dos parâmetros trazidos pela Lei 12.506/2011 para todas as situações jurídicas que se **consolidaram** entre a promulgação da Constituição e a edição da referida lei. Em primeiro lugar, a mora legislativa pressupõe certo lapso temporal de inação, o que não estaria configurado tão logo promulgada a Constituição, mas, além disso, muitas situações já se **consolidaram** de tal modo que a Constituição também lhes atribui proteção, a título de **ato jurídico perfeito** ou de **coisa julgada**” (fls. 48 do acórdão).

153 Cf. MI 712, Rel. Min. Eros Grau, MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, e MI 670, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007, *Inf. 485/STF*.

154 *Tratado de direito constitucional*, v. 1, p. 313.

155 Cf. art. 7.º, I a III, da Lei n. 9.507/97.

156 *Elementos de direito constitucional*, p. 212.

157 “À vista do disposto na Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do *habeas data*, tal ação só tem cabimento diante da recusa ao acesso às informações e da recusa em fazer-se a retificação ou anotação no cadastro do interessado (art. 8.º, parágrafo único). Desse modo, a Turma negou provimento ao recurso pela falta de interesse de agir do recorrente, já que, no caso, não houve uma pretensão resistida. Precedente citado: RHD 22-DF (*DJU* de 27.9.91). RHD 24-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, 28.11.97” (*Inf. 94/STF*).

158 Conforme redação determinada pela **EC n. 23, de 02.09.1999**.

159 “Art. 157. Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra eles **ação popular**, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida na Lei”.

160 Rodolfo de Camargo Mancuso, *Ação popular*, 4. ed., p. 52. Cf. interessante evolução histórica do instituto trazida por José Afonso da Silva, *Ação popular constitucional*, p. 28-39.

161 A Lei n. 4.717, de 29.06.1965, recepcionada pela CF/88, regulamenta a ação popular. A história do Direito romano guarda a **origem** da ação popular. Cabe lembrar que, sem constituir instrumento de participação política, a Constituição do Império de 1824 previa, em sentido amplo, a **ação penal popular** nas hipóteses de *suborno, peita, peculato* ou *concussão*, nos termos do art. 157 e conforme visto acima.

162 Ada Pellegrini Grinover, com a maestria que lhe é peculiar, observava que “a ação popular garante, em última análise, o **direito democrático de participação do cidadão na vida pública**, baseando-se **no princípio da legalidade dos atos administrativos** e no conceito de que a **coisa pública é patrimônio do povo**; já nesse ponto nota-se um estreito parentesco com as ações que visam à tutela jurisdicional dos interesses difusos, vistas como expressão de participação política e como meio de apropriação coletiva de bens comuns” (A tutela jurisdicional dos interesses difusos, *Revista de Processo*, São Paulo, n. 14-15, p. 38, abr./set. 1979). Ver ainda, pioneiramente atribuindo à ação popular o enfoque de **tutela jurisdicional de interesses difusos**, José Carlos Barbosa Moreira, Ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados “interesses difusos”, in *Temas de direito processual*, p. 110-123.

163 *Vide* art. 1.º, *caput*, da Lei da Ação Popular.

164 *Elementos de direito constitucional*, p. 200.

165 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 20. ed., p. 462.

166 Rodolfo de Camargo Mancuso, *Ação popular...*, 4. ed., p. 100. Em igual sentido, após interessante análise, cf. André Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, p. 683 e s. Cf., ainda, Clóvis Beznos, *Ação popular e ação civil pública*, p. 45, e Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior, *Curso de direito constitucional*, 6. ed., p. 167.

167 Cf. julgamento da ação popular que buscava atacar decreto presidencial que demarcou área indígena denominada **Raposa Serra do Sol** (Rcl 3.813/RR, Rel. Min. Carlos Britto, j. 28.06.2006. Precedentes citados: ACO 359 QO/SP, *DJU* de 11.03.1994; Rcl 424/RJ, *DJU* de 06.09.96; Rcl 2.833/RR, *DJU* de 05.08.2005 e Rcl 3.331/RR, *Inf. 433/STF*). Ainda, cf. ACO 622, ação popular que buscava declarar a nulidade da *Res. n. 507/2001*, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se instituiu CPI para apurar as causas do **acidente da plataforma P-36 da PETROBRAS**, localizada na Bacia de Campos.

168 Cf. indicação no *Inf. 443/STF*.

169 No mesmo sentido, cf.: AO 1.137 AgR/DF (*DJU* de 19.08.2005); AO 1.139 AgR/DF (*DJU* de 19.08.2005); MS 25.087/SP (*DJU* de 11.05.2007); MS 26.006 AgR/DF (*DJE* de 15.02.2008); Pet 3.986 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 25.06.2008 (*Inf. 512/STF*).

170 O exame 102.º/OAB exigia o mesmo conhecimento em questão referente ao art. 5.º, XI.

171 OAB/101.º/102.º também exigiam conhecimento sobre o mandado de injunção.

- 1 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 5. ed., p. 183.
- 2 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 186-187.
- 3 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 187.
- 4 Remetemos o ilustre leitor para o aprofundamento da matéria nos livros de **direito e processo do trabalho**, até porque foge do nosso objetivo abordar em detalhes os referidos temas.
- 5 Cf. art. 10, I e II, ADCT e LC n. 146/2014.
- 6 **Art. 1.º da Lei n. 5.627/2009, do Estado do Rio de Janeiro**: “No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho **que o fixe a maior**, será de: (...)”. Analisando esse dispositivo, decidiu o STF: “... A expressão ‘que o fixe a maior’ contida no *caput* do art. 1.º da Lei estadual 5.627/2009 tornou os valores fixados na lei estadual aplicáveis, *inclusive*, aos trabalhadores com pisos salariais estabelecidos em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho inferiores a esse. **A inclusão da expressão extrapola os limites da delegação legislativa advinda da LC 103/2000, violando, assim, o art. 22, I e parágrafo único, da CF, por invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho**” (ADI 4.391, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2011, Plenário, DJE de 20.06.2011). Devemos informar que a referida Lei Estadual n. 5.627/2009 foi revogada pela Lei n. 5.950/2011-RJ, estando atualmente a matéria regulada pela Lei n. 6.402/2013-RJ.
- 7 Para aprofundamento do assunto, cf. interessante voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes: **ADPF 151-MC**, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 02.02.2011, Plenário, DJE de 06.05.2011 (**mérito da matéria pendente de julgamento**).
- 8 As expressões são de Canotilho, em trabalho elaborado para o *Colóquio de Madrid* sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, realizado entre 22 e 26 de abril de 1996. Para leitura do referido estudo, cf. J. J. Gomes Canotilho, “Metodologia fuzzy” e “camaleões normativos” na problemática atual dos direitos econômicos, sociais e culturais, in *Estudos sobre direitos fundamentais*, p. 97-113.
- 9 J. J. Gomes Canotilho, *Estudos sobre direitos fundamentais*, p. 99 — original sem grifos.

- 10 J. J. Gomes Canotilho, *Estudos sobre direitos fundamentais*, p. 100-101 — original sem grifos.
- 11 Sugerimos a leitura do voto do Min. Gilmar Mendes na **SL 47 AgR**, j. 17.03.2010, estabelecendo diversos **parâmetros** para **solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde**, bem como a confirmação da responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde e, diante da não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública, a determinação de política pública pelo Poder Judiciário, em razão da possibilidade de ocorrência de dano inverso.
- 12 J. J. G. Canotilho, *Direito constitucional e teoria da Constituição*, 6. ed., p. 468.
- 13 Élica Graziane Pinto e Ingo Wolfgang Sarlet, Regime previsto na EC 86/2015 deve ser piso e não o teto de gasto em saúde, *Revista Consultor Jurídico* de 24.03.2015, p. 4, acesso em 08.05.2015.
- 14 **RE 271.286-AgR**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000, 2.^a Turma, *DJ* de 24.11.2000. No mesmo sentido: **STA 175-AgR**, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. 17.03.2010, Plenário, *DJE* de 30.04.2010.
- 15 Querido leitor, àquele que se prepara para os **concursos da defensoria pública**, o tema ganha importante relevância.
- 16 A íntegra dessa decisão pode ser lida em *Notícias STF*, 24.03.2010.

- 1 “*Cidadania* ... qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política ... Nacionalidade é conceito mais amplo do que cidadania, e é pressuposto desta, uma vez que só o titular da nacionalidade brasileira pode ser cidadão” (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 305).
- 2 Adotada e proclamada pela Res. n. 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10.12.1948.
- 3 No território nacional se incluem: “... 1) as terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, como rios, lagos, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial, formando o território propriamente dito; 2) os navios e aeronaves de guerra onde quer que se encontrem; 3) os navios mercantes brasileiros em alto-mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro; 4) as aeronaves civis brasileiras em voo sobre o alto-mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaços aéreos estrangeiros” (Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, p. 57, apud José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 290).
- 4 *Curso de direito constitucional*, 3. ed., p. 718.
- 5 A aquisição da nacionalidade dá-se no momento da fixação da residência no País; este o fato gerador da nacionalidade. No entanto, esta fica sujeita à opção confirmativa. Assim, a condição de brasileiro nato fica suspensa até a implementação da condição. Nesse sentido, cf. José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 293.
- 6 Lembramos o art. 69, § 4.º, da Constituição de 1891, que dizia: “São cidadãos brasileiros: os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro de seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem”.
- 7 O procedimento, inclusive os formulários para requerimentos a autoridades responsáveis pode ser consultado no site do **Ministério da Justiça**: <www.mj.gov.br/data/Pages/MJ33FCEB63PTBRIE.htm>.
- 8 “Art. 112. São condições para a concessão da naturalização (renumerado pela Lei n. 6.964, de 9.12.81): I — capacidade civil, segundo a lei brasileira; II — ser registrado como permanente no Brasil; III — residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização, podendo ser reduzido

ou dispensado nos termos da lei; IV — ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; V — exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família; VI — bom procedimento; VII — inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a 1 (um) ano; e VIII — boa saúde, não sendo esta exigida a nenhum estrangeiro que residir no País há mais de dois anos”.

9 Ou seja, originários de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Açores, Cabo Verde, Príncipe, Goa, Gamão, Dio, Macau e Timor (cf. José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 332).

10 Inicialmente previa-se o prazo de **30 anos**, que foi diminuído para **15 anos** pela EC de Revisão n. 3/94.

11 Conforme decidiu o STF, “a ausência temporária não significa que a residência não foi contínua, pois há que distinguir entre residência contínua e permanência contínua” (Pleno, Ag. 32.074-DF, Rel. Min. Hermes Lima, j. 04.02.1965).

12 *Curso de direito constitucional positivo*, p. 295.

13 H. Accioly, G. E. do Nascimento e Silva e P. B. Casella, *Manual de direito internacional público*, 17. ed., p. 499.

14 Naturalmente, a **extradição ativa**, ou seja, quando o requerimento de entrega é feito pelo Estado brasileiro ao Estado estrangeiro, não está vedada na Constituição. Assim, se um brasileiro nato comete um crime no Brasil e, tendo sido condenado, foge para um outro país, pelo direito brasileiro o pedido de extradição de lá para cá não está proibido.

15 H. Accioly, G. E. do Nascimento e Silva e P. B. Casella, *Manual de direito internacional público*, 17. ed., p. 501. Importante notar que o **Tribunal Penal Internacional — TPI**, lembrando que o Brasil se submete a sua jurisdição (art. 5.º, § 4.º), adota um **regime diferenciado**, mais abreviado, que a doutrina vem denominando **entrega** (*surrender*), não se confundindo com a extradição (cf. *item 14.10.25* e Valério de O. Mazzuoli, *Curso de direito internacional público*, 2. ed., p. 603 e 740, bem como Marcelo D. Varella, *Direito internacional público*, p. 185). O tema está para ser resolvido pelo STF na **Pet. 4.625**, interposta pelo TPI em 16.07.2009, que requer a eventual prisão e entrega do Presidente do Sudão, acusado de ter cometido crimes contra a humanidade e de guerra, caso ele entre no território brasileiro (**matéria pendente**).

16 Também no sentido de não se exigir sentença penal condenatória para o acolhimento do pedido de extradição, no direito norte-americano, podemos lembrar o instituto do *indictment*, que se equipara à **pronúncia** do direito brasileiro. O STF tem entendido esse ato formal como **suficiente** para se legitimar o pedido de *extradição passiva instrutória* (cf. o precedente no julgamento da **Ext 280**, Rel. Min. Adaucto Cardoso, j. 26.03.1969, Plenário, *DJ* de 12.09.1969, reafirmado em outros tantos julgados, como na **Ext 1.069**, j. 09.08.2007).

17 Devemos alertar que o **art. 81 da Lei n. 6.815/80**, em sua redação original, que estabelecia a atribuição do Ministro da Justiça para ordenar a prisão do extraditando, colocando-o à disposição do Supremo Tribunal Federal, **não foi recepcionado pela CF/88**, na medida em que, conforme se apontou, cabe ao **Ministro Relator do STF** decretar a prisão.

18 “EMENTA: Extradição ativa. Falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Pedido formulado por pessoa física. Inadmissibilidade. Ausência de legitimidade ativa. Prerrogativa que apenas assiste a Estados estrangeiros. Extradição não conhecida. **O Supremo Tribunal Federal, no sistema constitucional brasileiro, somente dispõe de competência originária para processar e julgar as extradições passivas, requeridas, ao Governo do Brasil, por Estados estrangeiros.** Não compete à Suprema Corte apreciar, nem julgar da legalidade de extradições ativas, pois estas deverão ser requeridas, diretamente, pelo Estado brasileiro, aos Governos estrangeiros, em cujo território esteja a pessoa reclamada pelas autoridades nacionais. Os pedidos de extradição, por envolverem uma relação de caráter necessariamente **intergovernamental**, somente podem ser formulados por Estados soberanos, falecendo legitimação, para tanto, a meros particulares” (**Ext 955**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17.12.2004, Plenário, *DJ* de 1.º.02.2005).

19 “O **postulado da especialidade**, precisamente em função das razões de ordem político-jurídica que justificam a sua formulação e previsão em textos normativos, assume inegável sentido tutelar, pois **destina-se a proteger**, na concreção do seu alcance, **o súdito estrangeiro** contra a instauração de persecuções penais eventualmente arbitrárias. *Convenção Europeia Sobre Extradição* (Art. 14) e *Tratado de Extradição Brasil — Suíça* (Art. V). Magistério da doutrina” (**Ext-571-extensão**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.06.1995, Plenário, *DJ* de 04.08.1995).

20 De acordo com o **art. 5.º, XLVII, da CF/88**, não haverá penas: **a)** de morte, salvo em

caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; **b)** de caráter perpétuo; **c)** de trabalhos forçados; **d)** de banimento; **e)** cruéis. Assim, o Estado estrangeiro deverá assumir o compromisso de **não aplicar** quaisquer das penas que são vedadas pelo ordenamento brasileiro.

21 “Extradição e dupla tipicidade. A possível diversidade formal concernente ao *nomen juris* das entidades delituosas não atua como causa obstativa da extradição, desde que o fato imputado constitua crime sob a dupla perspectiva dos ordenamentos jurídicos vigentes no Brasil e no Estado estrangeiro que requer a efetivação da medida extradicional. O **postulado da dupla tipicidade** — por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição — **impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente**. O que realmente importa, na aferição do postulado da dupla tipicidade, é a presença dos **elementos estruturantes do tipo penal** (*essentialia delicti*), tais como definidos nos preceitos primários de incriminação constantes da legislação brasileira e vigentes no ordenamento positivo do Estado requerente, **independentemente da designação formal por eles atribuída aos fatos delituosos**” (Ext 953, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.09.2005, Plenário, DJ de 11.11.2005).

22 “O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os atentados contra Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, sequestro de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política ou social” (art. 78, § 3.º, do Estatuto dos Estrangeiros).

23 Cf. *Notícias do STF* (18.11.2009 e 16.12.2009), bem como *Informativos* (558, 567 e 568). Ainda, cf. o acórdão com densas discussões em **686 páginas** (só de acórdão!): Ext 1.085, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.12.2009, Plenário, DJE de 16.04.2010.

24 Texto publicado na *Revista Consultor Jurídico*, em 29.12.2009, disponível em: <www.conjur.com.br>.

25 Francisco Rezek, *Direito internacional: curso elementar*, p. 204.

26 A decisão do STF foi proferida em 16.12.2009. O acórdão publicado em 16.04.2010. O ato do ex-Presidente, somente em 30.12.2010. Curiosamente, levou-se **8 meses** para deliberar!

27 O parágrafo único do referido artigo entende também passível de expulsão o estrangeiro

que: **a)** praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil; **b)** havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação; **c)** entregar-se à vadiagem ou à mendicância; **d)** desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.

28 A partir do julgamento do **HC 31.449**, o **STJ** vem adotando **interpretação sistemática** do referido art. 75, § 1.º, da Lei n. 6.815/80, em face da CF, do ECA e da Convenção sobre os Direitos da Criança: “EMENTA: (...). 1. A regra do art. 75, II, *b*, da Lei 6.815/80 deve ser interpretada sistematicamente, levando em consideração, especialmente, os princípios da CF/88, da Lei 8.069/90 (ECA) e das convenções internacionais recepcionadas por nosso ordenamento jurídico. 2. **A proibição de expulsão de estrangeiro que tenha filho brasileiro objetiva resguardar os interesses da criança, não apenas no que se refere à assistência material, mas à sua proteção em sentido integral, inclusive com a garantia dos direitos à identidade, à convivência familiar, à assistência pelos pais**. 3. Ordem concedida” (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.05.2004). Nesse sentido, cf. HC 88.882/STJ e AgRg no HC 115.603/STJ.

29 Nesse sentido: “A existência de filha brasileira só constitui causa impeditiva da expulsão de estrangeiro, quando sempre a teve sob sua guarda e dependência econômica, **mas desde que a tenha reconhecido antes do fato que haja motivado a expedição do decreto expulsório**” (**HC 82.893**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 17.12.2004, Plenário, *DJ* de 08.04.2005). No mesmo sentido: HC 110.849, j. 10.04.2012, 2.ª T.; HC 100.793, j. 02.12.2010, Plenário; HC 97.095, j. 19.08.2010, Plenário; HC 85.203, j. 06.08.2009, Plenário etc.

30 Nesse sentido, destacamos liminar concedida pelo Min. Celso de Mello, em 27.11.2012, no julgamento do **HC 114.901**, fundada no dever constitucional de **preservar a unidade** e de **proteger a integridade da entidade familiar**, mesmo que não fundada no casamento.

31 Cf. **HC 54.718**, Plenário do STF, j. 15.12.1976, e **HC 87.007-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 26.10.2005, *DJ* de 08.11.2005.

32 Francisco Rezek, *Direito internacional público: curso elementar*, p. 221.

33 O inciso VII do § 3.º do art. 12 da CF/88 foi introduzido pela **EC n. 23, de 02.09.1999**.

34 **Art. 112, § 2.º**: “Verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de qualquer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta Lei, será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação penal cabível pela infração cometida. **§ 3.º** A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior processar-se-á administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante representação fundamentada, concedido ao naturalizado, para defesa, o prazo de quinze dias, contados da notificação”.

35 José Afonso da Silva (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 207) sugere apenas as regras do art. 36 da Lei n. 818/49. E observa: “... a reaquisição da nacionalidade opera a partir do decreto que a conceder, não tendo efeito retroativo, mas o readquirente recupera a condição que perdera: se era brasileiro nato, voltará a ser brasileiro nato; se naturalizado, retomará essa qualidade” (op. cit., 17. ed., p. 335). Já Alexandre de Moraes entende que a reaquisição só se dará através do processo de naturalização, tornando-se, inclusive o ex-brasileiro nato, agora, naturalizado (*Direito constitucional*, p. 213-214).

36 Lembramos que no Concurso 80.º/MP/SP se exigia o mesmo conhecimento. Apenas alertamos que a **EC n. 23, de 02.09.1999**, acrescentou mais um cargo a ser exercido exclusivamente por brasileiro nato, qual seja, o de **ministro de Estado da Defesa** (art. 12, § 3.º, VII).

- 1 Clássica é a sempre lembrada definição de Pimenta Bueno, para quem os **direitos políticos** são “prerrogativas, atributos, faculdades, ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos. São o *Jus Civitatis*, os direitos cívicos, que se referem ao Poder Público, que autorizam o cidadão ativo a participar na formação ou exercício da autoridade nacional, a exercer o direito de vontade ou eleitor, os direitos de deputados ou senador, a ocupar cargos políticos e a manifestar suas opiniões sobre o governo do Estado” (*Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*, p. 458).
- 2 *Revista da PGE/SP*, n. 336, dez. 1993.
- 3 Remetemos o nosso querido leitor para o *item 9.13.3.4*, no qual o instituto da **iniciativa popular** é aprofundado.
- 4 E complementam: “a ADEPOL afirma que a proibição da comercialização impede o exercício do comércio assegurado pela Constituição Federal (art. 170, *caput*, e parágrafo único). Registra que o comércio de armas, devidamente regulamentado, gerou a aquisição de direito adquirido e que seria inconstitucional seu término por meio de lei ordinária. A proibição da venda de armas ao cidadão comum, em caráter permanente, inviabiliza a produção e o comércio de armas, resultando em ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 24, V, da CF), diz a entidade. Argumenta, ainda, que são direitos básicos do cidadão a segurança e a propriedade e a posse de armas e munições defensivas mediante as cautelas disciplinadas em lei. ‘Até porque o Estado não é capaz de garantir a segurança de todos todo o tempo’, sustenta a ADEPOL. Por fim, a entidade requer a suspensão da legislação questionada ‘pelos tumultos que essas normas vêm causando ao pretender impedir o exercício de profissão lícita e pelo prejuízo que a aplicação desses preceitos causa ao comércio interno e às indústrias fornecedoras’” (*Notícias STF*, 13.07.2005).
- 5 Jorge Hélio Chaves de Oliveira, *Olhar jurídico*, Fortaleza, 14 set. 2005. Disponível em: <<http://www.noolhar.com/colunas/olharjuridico/514990.html>>. Acesso em: 20.09.2005.
- 6 Até 1913, o Brasil possuía apenas 1 fuso horário. O **Decreto n. 2.784/1913** dividiu o território do país, no que diz respeito à **hora legal**, em 4 fusos distintos. A citada Lei n. 11.662/2008 reduziu para 3 fusos, retirando o Acre e a Amazônia ocidental do 4.º fuso (que foi extinto). Após manifestação popular no Estado do Acre, a Lei n. 12.876/2013 restabeleceu os 4 fusos originários, tendo como parâmetro o meridiano de *Greenwich*. A citada Lei n. 11.662/2008, de autoria do então Senador Tião Viana (PT-AC), que depois

veio a se tornar governador do Estado, reduziu de 2 para 1 hora a diferença em relação ao horário oficial de Brasília, sob o fundamento de sugeridos prejuízos econômicos, sociais e culturais, especialmente durante a vigência do horário de verão, quando a diferença passava a ser de três horas. Conforme visto, atualmente a diferença (fora do horário de verão) é de 2 horas.

7 José Afonso da Silva, *Poder constituinte e poder popular*, p. 21.

8 Walber de Moura Agra, *Curso de direito constitucional*, 5. ed., p. 297.

9 *Constituição Federal anotada*, p. 423.

10 “*Cidadania* ... qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política ... Nacionalidade é conceito mais amplo do que cidadania, e é pressuposto desta, uma vez que só o titular da nacionalidade brasileira pode ser cidadão” (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 305).

11 Conscritos são os convocados, ou melhor, os recrutados, para o serviço militar obrigatório. No caso de se engajarem no serviço militar permanente não são conscritos, e, em decorrência, José Afonso da Silva observa que “... soldados engajados, cabos, sargentos, suboficiais e oficiais das Forças Armadas e Polícias Militares são obrigados a se alistarem como eleitores” (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 306).

12 Nos termos do art. 10, § 2.º, da **Res. n. 22.156/TSE**, “a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse (Lei n. 9.504/97, art. 11, § 2.º)”. Em igual sentido o art. 9.º, § 2.º da Res. n. 21.608/TSE.

13 Não confundir **inelegibilidade** com **inalistabilidade** ou **incompatibilidade**. Vejamos: a) inelegibilidade → obsta a elegibilidade; b) inalistabilidade → impede o exercício da capacidade eleitoral ativa (direito de ser eleitor); c) incompatibilidade → já eleito, impede-se o exercício do mandato.

14 *Vide* **LC n. 64/90**, alterada pela LC n. 81/94, bem como pela LC n. 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”).

15 Na lapidar lição de José Afonso da Silva, “os estrangeiros não adquirem *direitos políticos*, só atribuídos a brasileiros natos e naturalizados. Portanto, não são alistáveis eleitores nem, por consequência, podem votar ou ser votados (art. 14, § 2.º). Por isso

também é que não podem ser membros de partidos políticos, que é uma prerrogativa da cidadania” (*Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 340-341).

16 Este também é o posicionamento de Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior (*Curso de direito constitucional*, p. 163).

17 Sendo o STF o guardião da Constituição, este deve ser o posicionamento a ser adotado em provas objetivas. Nas provas subjetivas, o candidato poderá expor os dois pontos de vista, justificar e posicionar-se adotando um. Cf. a posição do STF na ADI **1.805-MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, 26.03.1998**, *Inf. 104/STF*, Brasília, 23 a 27.03.1998.

18 *Notícias STF*, 07.04.2003 — 17h40 (<www.stf.gov.br>).

19 “O cidadão pode, excepcionalmente, ser privado, *definitivamente* ou *temporariamente*, dos direitos políticos, o que importará, como efeito imediato, na perda da cidadania política. Deixa, imediatamente, de ser eleitor, se já o era, ou se torna inalistável como eleitor, com o que, por consequência, fica privado da elegibilidade e de todos os direitos fundados na qualidade de eleitor” (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 335).

20 Destacamos importante questão a ser discutida pelo STF no julgamento do **RE 601.182** (com repercussão geral) interposto pelo MP de Minas Gerais, consistente na aplicação ou não do art. 15, III (suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado), na **hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**. No caso, o TJMG entendeu não haver a suspensão dos direitos políticos. “Considerou que não há qualquer incompatibilidade em relação ao pleno exercício dos seus direitos políticos, ‘cuja relevante importância só permite o tolhimento em situações que materialmente os inviabilizem’. Por isso, com base nos **princípios** da **isonomia**, da **dignidade da pessoa** e da **individualização da pena**, concluiu pela manutenção dos direitos políticos do apenado” (*Notícias STF de 09.03.2011 — pendente de julgamento de mérito*).

21 *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 386.

22 José Afonso da Silva (*Curso de direito constitucional positivo*, p. 207) sugere apenas as regras do art. 36 da Lei n. 818/49. E observa: “... a reaquisição da nacionalidade opera a partir do decreto que a conceder, não tendo efeito retroativo, mas o readquirente recupera a condição que perdera: se era brasileiro nato, voltará a ser brasileiro nato; se

naturalizado, retomará essa qualidade” (op. cit., 17. ed., p. 335). Já Alexandre de Moraes entende que a reaquisição só se dará pelo processo de naturalização, tornando-se, inclusive o ex-brasileiro nato, agora, naturalizado (*Direito constitucional*, p. 213-214).

[23](#) Nesse sentido, José Sérgio Monte Alegre, Ação popular não é direito político, *RDA* 189/123-138.

[24](#) Nesse sentido, José Sérgio Monte Alegre, Ação popular não é direito político, *RDA* 189/123-138.

- 1 Celso Ribeiro Bastos, *Curso de direito constitucional*, p. 275.
- 2 *Curso de direito constitucional positivo*, 17. ed., p. 395.
- 3 José Afonso da Silva, partilhando desse entendimento, percebe certa dificuldade em reconhecer qualquer outra natureza política aos partidos políticos que não a de **pessoa jurídica de direito privado**, especialmente diante do fato de serem organizações associativas formadas pela adesão voluntária de particulares e destinadas não propriamente a realizar fins públicos, mas fins **políticos**. “Os partidos somente prestam serviços públicos quando no exercício das funções governamentais, mas aí não são senão instrumentos da prestação desses serviços, que não são deles, mas do Estado, dos órgãos governamentais, que, com eles, não se confundem” (*Curso de direito constitucional positivo*, cit., 17. ed., p. 404 — grifamos). O art. 1.º da Lei n. 9.096/95 expressamente declara o partido político como **pessoa jurídica de direito privado**.
- 4 “Extraí-se do princípio da liberdade de criação e transformação de partidos políticos contido no *caput* do art. 17 da CR o fundamento constitucional para reputar como legítimo o entendimento de que, na **hipótese de criação de um novo partido**, a novel legenda, para fins de acesso proporcional ao rádio e à televisão, **leva consigo a representatividade dos deputados federais que, quando de sua criação, para ela migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos**. Não há razão para se conferir às hipóteses de criação de nova legenda tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos (art. 47, § 4.º, da Lei das Eleições), já que todas essas hipóteses detêm o mesmo patamar constitucional (art. 17, *caput*, da CF/88), cabendo à lei, e também ao seu intérprete, preservar o sistema. Se se entende que **a criação de partido político autoriza a migração dos parlamentares para a novel legenda**, sem que se possa falar em infidelidade partidária ou em perda do mandato parlamentar, essa mudança resulta, de igual forma, na alteração da representação política da legenda originária. Note-se que a Lei das Eleições, ao adotar o marco da última eleição para deputados federais para fins de verificação da representação do partido (art. 47, § 3.º, da Lei 9.504/1997), não considerou a hipótese de criação de nova legenda. Nesse caso, o que deve prevalecer não é o desempenho do partido nas eleições (critério inaplicável aos novos partidos), mas, sim, a representatividade política conferida aos parlamentares que deixaram seus partidos de origem para se filiarem ao novo partido político, recém-criado. Essa interpretação prestigia, por um lado, a **liberdade constitucional de criação de partidos políticos** (art. 17, *caput*, da CF/88) e, por outro,

a representatividade do partido que já nasce com representantes parlamentares, tudo em consonância com o sistema de representação proporcional brasileiro” (ADI 4.430, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.06.2012, Plenário, DJE de 19.09.2013).

5 CTA n. 715: Consulta formulada pelos Deputados Federais Miro Teixeira, José Roberto Batochio, Fernando Coruja e Pompeo de Mattos, considerando o que dispõe o art. 6.º da Lei n. 9.504/97, nos seguintes termos: “Pode um determinado partido político (partido A) celebrar coligação para eleição de Presidente da República com alguns outros partidos (partido B, C e D) e, ao mesmo tempo, celebrar coligação com terceiros partidos (E, F e G, que também possuem candidato à Presidência da República) visando à eleição de Governador de Estado da Federação? **Resposta:** EMENTA: Consulta. Coligações. Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de presidente da República **não** poderão formar coligações para eleição de governador de Estado ou do Distrito Federal, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital com outros partidos políticos que tenham, isoladamente ou em aliança diversa, lançado candidato à eleição presidencial. Consulta respondida negativamente”.

6 “Art. 6.º É facultado aos partidos políticos, **dentro da mesma circunscrição**, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.”

7 A petição da CONAMP continha **98 páginas** e sustentava a inconstitucionalidade com base em denso parecer do promotor *Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira*, destacando-se 3 teses: “**a)** artigo 16 da CF/88 como cláusula pétrea — vedação material implícita ao Poder Constituinte Derivado Reformador (**democracia** como princípio político-constitucional); **b)** artigo 16 da CF/88 como cláusula pétrea — vedação explícita ao Poder Constituinte Derivado Reformador (artigo 60, § 4.º, IV, CF/88); **c)** artigo 16 da CF/88 e a aplicação e vigência das normas no tempo (antinomia ou conflito de leis no tempo). Inexistência de hierarquia entre normas constitucionais. Aplicação da nova regra somente nas eleições gerais/Presidencial de 2010”.

8 A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), por outro lado, ajuizou, em 16.03.2006, a **ADPF 89**, buscando defender a regra trazida pela EC n. 52/2006 e a sua compatibilidade com o art. 16 da CF/88. Em seu pedido requereu que o STF determinasse a todos os juízes e tribunais que interpretassem o *caput* do art. 6.º da Lei federal n. 9.504/97 (Lei Eleitoral — coligações) no sentido de serem livres as coligações partidárias,

apontando, assim, como preceito fundamental violado, o parágrafo único do art. 1.º da CF/88 (a titularidade do poder pertence ao povo). Em **29.03.2006**, a Ministra relatora também **negou seguimento à aludida ADPF**, com a seguinte decisão: “(...) desponha-se, portanto, como real objeto da ADPF ora analisada, o próprio teor da EC 52/06, ato normativo plenamente examinável por meio de ADI ou de ADC. De fato, no julgamento da ADI n. 3.685, de minha relatoria, ocorrido na sessão de 22/03/06, o plenário desta corte, dando interpretação conforme à Constituição, fixou o entendimento de que a nova regra que extingue a chamada verticalização (CF, art. 17, § 1.º) somente poderá ser aplicada, nos termos do art. 16 da CF, após o transcurso de um ano da data de sua vigência. Conforme dispõe o art. 4.º, § 1.º, da L. 9.882/99, ‘não será admitida ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade’. Assim, sendo a pretensão da presente ADPF a busca da declaração de constitucionalidade da imediata aplicação da EC 52/06, mostra-se manifestamente incabível a via eleita, motivo pelo qual a ela nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1.º, do *RISTF*. Publique-se”.

9 Sobre o princípio da proibição do “atalhamento constitucional”, cf. *item 6.7.1.10* deste estudo.

10 Trata-se de transcrição das ementas dos referidos julgados: **MS 30.260** e **MS 30.272**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2011, Plenário, *DJE* de 30.08.2011.

- 1 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 758.
- 2 José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 29. ed., p. 828.
- 3 Sugerimos aos candidatos o aprofundamento das regras sobre saúde, previdência e assistência social nos livros de Direito Previdenciário.
- 4 Pedindo licença ao ilustre leitor, aqui costumamos brincar com os nossos queridos alunos concurseiros: “*pau que nasce torto nunca se endireita...*”.
- 5 Assim, muito cuidado aqueles que vão prestar concurso para PFN.
- 6 A última esperança estava na **ADI 4.071**, proposta pelo PSDB, que, além da questão de mérito, pedia a modulação dos efeitos. Contudo, em **10.10.2008**, o Min. Menezes Direito **extinguiu** a ação, justificando que a matéria já havia sido inteiramente julgada pelo Plenário do STF nos referidos mandados de segurança (*REs ns. 377.457 e 381.964*).
- 7 As idades indicadas no quadro estão nos termos da **Lei n. 11.274, de 06.02.2006**, que, ao modificar o art. 32 da Lei n. 9.394/96, determinou a ampliação da duração do ensino fundamental obrigatório para **9 anos**, gratuito na escola pública e iniciando aos 6 anos de idade. Contudo, conforme o art. 5.º da Lei n. 11.274/2006, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal teriam até **2010** para implementar a obrigatoriedade da duração de 9 anos para o ensino fundamental e a abrangência da pré-escola. Nesse sentido, até 2010 as idades indicadas poderiam variar de 0-3 anos (creche); 4-6 anos (pré-escola); 7-14 anos (ensino fundamental) e 15-17 anos (ensino médio).
- 8 Cf. Assessoria de Comunicação Social do MEC, *Notícias* 07.12.2006, disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb>>.
- 9 Cf. Assessoria de Comunicação Social do MEC, *idem*.
- 10 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 802.
- 11 Remontando à frase do poeta romano *Juvenal* (com o novo significado que tomou ao longo do tempo), amigo concursário, “*mens sana in corpore sano*” (mente sã em corpo são). Continue na luta, mas na luta estratégica, e tentando não perder a qualidade de vida, direito fundamental previsto na CF/88 (sabemos que é difícil, mas conte conosco! **Carpe Diem** — *desfrute o momento*, procure encontrar prazer nessa fase de preparação, pois ela passará e tudo vai dar certo!).
- 12 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, *Curso de direito*

constitucional, 10. ed., p. 493.

- 13 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. *Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa*, p. 1238.
- 14 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 817.
- 15 Cf. TST-RR-643.344/2000, *DJ* de 12.09.2003, 3.^a Turma, Min. Relator Carlos Alberto Reis de Paula; TST-AIRR-738.470/2001, *DJ* de 06.09.2001, 3.^a Turma, Min. Relator Carlos Alberto Reis de Paula; TST-AIRR-1562/1998-065-01-40.8, *DJ* de 11.10.2007, 2.^a Turma, Min. Relator Renato de Lacerda Paiva; AIRR-448/2002-011-09-40, *DJ* de 07.12.2007, Min. Barros Levenhagen.
- 16 Cf. Leis ns. 8.248/91, 8.387/91, 9.257/96, 8.661/93 e 10.637/2002; Decreto n. 6.262/2007 etc.
- 17 Cf. interessante julgado do STF: “Dispositivo da Constituição estadual que, ao destinar 2% da receita tributária do Estado de Mato Grosso à mencionada entidade de fomento científico, o fez nos limites do art. 218, § 5.º, da Carta da República, o que evidencia a improcedência da ação nesse ponto” (ADI 550, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 29.08.2002, *DJ* de 18.10.2002).
- 18 ADI 3.510, Rel. Min. Carlos Britto, j. 28 e 29.05.2008, *Inf. 508/STF*.
- 19 “Não se compreende, no rol de competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, *ut* art. 23 da CF, a matéria concernente à disciplina de ‘diversões e espetáculos públicos’, que, a teor do art. 220, § 3.º, I, do Diploma Maior, compete à **lei federal** regular, estipulando-se, na mesma norma, que ‘caberá ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada’. (...) Ao **Município** fica reservada a competência, *ut* art. 30, I, da Lei Maior, para exercer **poder de polícia** quanto às diversões públicas, no que concerne à localização e autorização de funcionamento de estabelecimentos que se destinem a esse fim” (RE 169.247, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 08.04.2002, *DJ* de 1.º.08.2003).
- 20 “Constitucional. Lei federal. Restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, etc. Impugnação do dispositivo que define o que é bebida alcoólica para os fins de propaganda. Alegada discriminação legal quanto às bebidas com teor alcoólico inferior a treze graus *Gay Lussac*. A subtração da norma do corpo da lei implica em atuar este Tribunal como legislador positivo, o que lhe é vedado. Matéria para ser dirimida no

âmbito do Congresso Nacional” (ADI 1.755, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 15.10.1998, *DJ* de 18.05.2001).

21 Cf. **Parecer CCJ n. 242/02**, *DSF* de 11.04.2002, p. 4066-99. Na votação em primeiro turno, o então Senador José Fogaça, autor da referida Emenda de Redação n. 3, destacou: “... no que tange ao capital social da empresa, há uma necessidade de respeitar os 70% para o capital de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, assegurando que este mínimo seja absoluta e rigorosamente respeitado” (*DSF* de 09.05.2002, p. 7594).

22 Nos termos do art. 211 da Lei n. 9.472/97, a outorga dos serviços de *radiodifusão sonora e de sons e imagens* fica **excluída da jurisdição da ANATEL**, permanecendo no âmbito de competências do **Poder Executivo**, devendo a Agência elaborar e manter os respectivos planos de distribuição de canais, considerando, inclusive, os aspectos concernentes à evolução tecnológica.

23 O serviço de **TV a Cabo** tem regramento próprio nos termos da Lei n. 8.977/95.

24 *Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre* — conjunto de padrões tecnológicos a serem adotados para transmissão e recepção de sinais digitais terrestres de radiodifusão de sons e imagens.

25 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 830-831.

26 Conforme se verifica no site do **Ministério das Comunicações** (<<http://www.mc.gov.br>>, no ícone *radiodifusão — perguntas frequentes*), no tocante à radiodifusão **comercial**, “há 2 modos de conceder a outorga de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens (televisão): permissão e concessão. A **permissão** é utilizada para a outorga de serviço de radiodifusão de caráter local e é assinada pelo Ministro das Comunicações. Já a **concessão** é utilizada para a outorga de serviços de caráter regional e é de responsabilidade do Presidente da República”. Como muito bem anotam Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky, “... nossa melhor doutrina tem entendido que as diferenças entre permissões e concessões não mais existiriam na medida em que ao prever expressamente prazos para as permissões a Constituição retirou-lhes o caráter de precariedade que lhes é característico”. Essa impressão, continuam, é reforçada pelo art. 175, parágrafo único, que estabelece o caráter especial das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, precedido, acrescente-se, sempre de licitação (*Curso de direito constitucional*, p. 265-266).

27 Cf. **ADI 3.944**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.08.2010, *DJE* de 30.09.2010.

- 28 Uadi Lammêgo Bulos, *Curso de direito constitucional*, p. 1316-1317.
- 29 Cf. Ramón Martín Mateo, *Derecho ambiental*, p. 71.
- 30 José Afonso da Silva, *Direito ambiental constitucional*, p. 2.
- 31 Guido F. S. Soares, *As responsabilidades no direito internacional do meio ambiente* — tese para professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP, p. 35.
- 32 Cf. importante trabalho de A. A. Cançado Trindade, Meio ambiente e desenvolvimento: formulação, natureza jurídica e implementação do direito ao desenvolvimento como um direito humano, *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*, p. 49-76. Sobre essa problemática, cf., ainda, A. A. Cançado Trindade, A. Kiss, Two major challenges of our time: human rights and the environment, *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*, n. 81/83, p. 147-150, e D. McGoldrick, Sustainable development and human rights: an integrated conception, *International and Comparative Law Quarterly*, v. 45, p. 796-818, out. 1996.
- 33 Sobre esta ideia cf. J. A. C. Salcedo, El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana, *Revista Española de Derecho Internacional*, p. 119-125.
- 34 Surge, então, a construção do **princípio do desenvolvimento sustentável**, consagrado inclusive internacionalmente, destacando-se, dentre outros diplomas, as declarações de *Estocolmo* (princípios 8.º e 18) e do *Rio de Janeiro* (princípios 3.º e 4.º). Cf., ainda, **ADI 3.540-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.09.2005, *DJ* de 03.02.2006.
- 35 E. Milaré, Tutela jurisdicional do meio ambiente, *RT* 676/49-50. Nesse mesmo sentido, afirma Francisco José Marques Sampaio: “Verificam-se, nas diversas áreas de atuação e expansão do conhecimento, esforços redobrados no sentido de se desenvolverem novos métodos de compatibilizar as necessidades e atividades humanas com a manutenção do equilíbrio ecológico, a conservação da natureza e a preservação da saúde das populações. No campo das ciências químicas, físicas e biológicas é notório o esforço empreendido por cientistas de muitos países para lograr êxito na árdua tarefa de inventar tecnologias capazes de alterar os sistemas produtivos, de modo que se tornem menos agressivos ao meio ambiente e capazes de contribuir para a verdadeira criação do chamado desenvolvimento econômico autossustentado, o ecodesenvolvimento” (O dano ambiental e a responsabilidade, *RDA* 185/41).
- 36 E. Milaré, *Direito do ambiente*, p. 211.

- 37 “Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento **ecológico**, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do Governo.”
- 38 Sérgio Ferraz, Responsabilidade civil por dano ecológico, *RDP* 49-50/35.
- 39 Cristiane Derani, *Direito ambiental econômico*, p. 267-268.
- 40 Conforme estabeleceu o STF, “... somente a **alteração** e a **supressão** do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1.º, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao **princípio da reserva legal**. É lícito ao **Poder Público** — qualquer que seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) — **autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos**, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1.º, III)” (cf. **ADI 3.540-MC**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.09.2005, *DJ* de 03.02.2006).
- 41 **CONAMA** — Conselho Nacional do Meio Ambiente, é um órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo e consultivo do Ministério do Meio Ambiente e foi instituído pela Lei n. 6.938/81, regulamentada pelo Decreto n. 99.274/90 e integra a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA (cf. <<http://www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm>>).
- 42 “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 182, § 3.º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Estudo de impacto ambiental. Contrariedade ao artigo 225, § 1.º, IV, da Carta da República. A norma impugnada, ao dispensar a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível com o disposto no mencionado inciso IV do § 1.º do artigo 225 da Constituição Federal” (ADI 1.086, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 07.06.2001, *DJ* de 10.08.2001).
- 43 Em igual sentido, cf. **ADI 1.856**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.05.2011, Plenário, *DJE* de 14.10.2011; **ADI 2.514**, j. 29.06.2005, *DJ* de 09.12.2005; **ADI 1.856**, j. 03.09.98, *DJ* de 22.09.2000.

- 44 Breve nota apresentada, conforme parecer do Deputado Federal Antônio Carlos Biffi, ao PL n. 7.291/2006, em 20.12.2007, na Comissão de Educação e Cultura (CEC) da Câmara dos Deputados.
- 45 PL n. 7.291/2006, em 20.12.2007, apresentado na Comissão de Educação e Cultura (CEC) da Câmara dos Deputados.
- 46 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) — Parecer do Relator, 15.12.2006.
- 47 Paulo A. L. Machado, *Direito ambiental brasileiro*, 6. ed., p. 41-42.
- 48 Sobre o tema da **responsabilidade penal**, cf. Luiz Regis Prado, *Crimes contra o ambiente*, passim, e *Direito penal ambiental: problemas fundamentais*, passim. Ainda nesse contexto, cf. Ivette Senise Ferreira, *Tutela penal do patrimônio cultural*, passim.
- 49 Deixando-se anotada a existência de dois precedentes nos quais o STF já havia vislumbrado a possibilidade de **responsabilização penal da pessoa jurídica**, nos termos do art. 225, § 3.º, da CF/88 (cf. *RE 473.045* e *HC 88.544*), em momento seguinte, no julgamento do **RE 548.181**, a primeira turma do STF, por maioria de votos (3 X 2), explicitamente, reconheceu a possibilidade de se processar penalmente a pessoa jurídica, no caso, a **PETROBRAS**, mesmo não tendo sido admitida a ação penal contra pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção. De acordo com a denúncia oferecida pelo MPF/PR, tratava-se de rompimento de duto em uma refinaria situada no município de Araucária (em 16.07.2000) e que teria levado ao derramamento de 4 milhões de litros de óleo cru, poluindo os rios Barigui, Iguaçu e áreas ribeirinhas (*Notícias STF*, 06.08.2013). Conforme informado, “**é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa**”. Com base nesse entendimento, a Primeira Turma, por maioria, conheceu, em parte, de recurso extraordinário e, nessa parte, deu-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido. Neste, a imputação aos dirigentes responsáveis pelas condutas incriminadas (Lei 9.605/1998, art. 54) teria sido excluída e, por isso, trancada a ação penal relativamente à pessoa jurídica. (...) No mérito, anotou-se que a tese do STJ, no sentido de que a persecução penal dos entes morais somente se poderia ocorrer se houvesse, concomitantemente, a descrição e imputação de uma ação humana individual, sem o que não seria admissível a responsabilização da pessoa jurídica, **afrontaria o art. 225, § 3.º, da CF**. Sublinhou-se que, ao se condicionar a imputabilidade da pessoa jurídica à da

pessoa humana, estar-se-ia quase que a subordinar a responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva condenação da pessoa física. Ressaltou-se que, ainda que se concluisse que o legislador ordinário não estabeleceria por completo os critérios de imputação da pessoa jurídica por crimes ambientais, não haveria como pretender transpor o paradigma de imputação das pessoas físicas aos entes coletivos” (RE 548.181, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06.08.2013, 1.^a T., Inf. 714/STF).

50 De acordo com a **Lei n. 9.605/98**: “**Art. 21.** As **penas** aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às **pessoas jurídicas**, de acordo com o disposto no art. 3.º, são: I — multa; II — restritivas de direitos; III — prestação de serviços à comunidade”. “**Art. 22.** As penas restritivas de direitos da **pessoa jurídica** são: I — suspensão parcial ou total de atividades; II — interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; III — proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações”.

51 “Art. 14, § 1.º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, **independentemente da existência de culpa**, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

52 Nesse sentido, cf. o nosso *Teoria geral da ação civil pública*, 2. ed., p. 353 e s.

53 RE 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.95, DJ de 22.09.1995 (RTJ 158/205). Cf., ainda, RE 267.817, RTJ 184/322; RE 471.110-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.11.2006, DJ de 07.12.2006; RE 300.244, Rel. Min. Moreira Alves, j. 20.11.2001, DJ de 19.12.2001, e RE 349.184, DJ de 07.03.2003.

54 Conforme anotou Érica Paula Barcha Correia, referido benefício tem **natureza indenizatória, e não previdenciária**. Segundo ensina, “na realidade, há um ressarcimento por dano considerado constitucionalmente e não provisão indicada legalmente para cobertura de contingências. O pagamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social, neste caso, é meramente operacional, não trazendo qualquer mudança na natureza jurídica do instituto” (in: J. J. Gomes Canotilho, Gilmar F. Mendes, Ingo W. Salet, Lenio L. Streck, *Comentários à Constituição do Brasil*, p. 2.231).

55 Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, 30. ed., p. 531.

56 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 850.

57 “A Lei n. 8.560/92 expressamente assegurou ao *Parquet*, desde que provocado pelo interessado e diante de evidências positivas, a possibilidade de intentar a ação de **investigação de paternidade**, legitimação essa decorrente da proteção constitucional conferida à família e à criança, bem como da **indisponibilidade** legalmente atribuída ao reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e de caráter patrimonial que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público para assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de não reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai” (RE 248.869, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.08.2003, DJ de 12.03.2004).

58 A Lei n. 8.971/94 citava o termo **companheiros**; a Lei n. 9.278/96 disciplinava a situação dos **conviventes**. O **Novo Código Civil** (Lei n. 10.406/2002, que para parte da doutrina revogou as outras duas leis — cf. Carlos Roberto Gonçalves, *Direito civil brasileiro*, v. VI, p. 536) abriu um título próprio para a união estável, tratando dos **companheiros** e reconhecendo, nos termos do art. 1.723, *caput*, como entidade familiar, a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

59 Art. 226, § 5.º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

60 Art. 227, § 6.º: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.

61 Carlos Roberto Gonçalves, *Direito civil brasileiro*, v. VI, p. 539-540.

62 Maria Berenice Dias, *União homossexual: o preconceito e a justiça*, p. 97.

63 **Art. 1.723 do CC**: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

64 Em relação ao registro da união estável prevista nos arts 1.723 a 1.727 do CC, mantida entre o homem e a mulher, ou entre **duas pessoas do mesmo sexo**, cf. **Provimento n. 37/2014-CNJ**.

65 Disponível em: <<http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf>>.

66 Para a íntegra da decisão da Ministra Ellen Gracie, cf. *Notícias STF*, 12.12.2007 — 09h30. Devemos saber que, em razão da Portaria n. 1.707/2008, do Ministério da Saúde,

que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o **processo transexualizador**, com previsão de ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão, a suspensão de tutela antecipada em referência (STA 185), bem como o agravo regimental interposto, foram julgados prejudicados pela **perda superveniente do objeto** (art. 21, IX, *RISTF*). Atualmente, o processo está disciplinado na Portaria n. 2.803/GM/MS/2013.

67 O art. 107, VII, do CP foi **revogado** pela **Lei n. 11.106/2005**. Cf. a “*Nova Lei do Estupro*” — **Lei n. 12.015/2009**, que passou a denominar “**estupro de vulnerável**” (art. 217-A, CP) a hipótese em que a **vítima é menor de 14 anos**, lembrando, também, que a lei estabeleceu como novo regime de apuração do crime de estupro a ação penal pública (condicionada ou incondicionada), situação que não admite a *renúncia* ou *perdão tácitos*, exclusivos da ação privada. Portanto, o exemplo trazido serve para mostrar o posicionamento do Estado no que respeita às relações familiares.

68 **Art. 1.º da Lei n. 11.340/2006**: “Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8.º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.

69 **Art. 33 da Lei n. 11.340/2006**: “Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no *caput*”.

70 **Art. 41, da Lei n. 11.340/2006**: “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”.

71 **Art. 12, I, da Lei n. 11.340/2006**: “Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar,

de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: I — ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada”.

72 Art. 16 da Lei n. 11.340/2006: “Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”.

73 Como se verificou, o art. 41 da Lei n. 11.340/2006 estatuiu que, aos crimes praticados com **violência doméstica e familiar contra a mulher**, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099/95. Assim, **não se aplica o art. 88 da Lei n. 9.099/95**, que estabelece depender de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

74 Agradecemos ao Dr. Yure Ubaldino Rocha Soares pelo envio do Acórdão. Para conhecer o parecer favorável do MP, cf. José Edivaldo Rocha Rotondano, O Ministério Público entende que casamento em centro espírita pode ter efeitos civis. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 914, 3 jan. 2006. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=666>>. Acesso em: 08.02.2008.

75 Nesse sentido, por todos, cf. Fernanda Tartuce, *Processo civil aplicado ao direito de família*, p. 224 e segs. Há corrente doutrinária ainda aceitando o cabimento da ação de separação judicial. O STF ainda não enfrentou o tema (pendente).

76 Flávio Tartuce, *O novo CPC e o direito civil: impactos, diálogos e interações*, p. 385. O entendimento firmado por Fernanda Tartuce, antes do CPC/2015, no sentido de não mais existir a ação de separação judicial — *vide* nota anterior, persiste diante do Novo CPC (informação confirmada por DM — *direct message* via *Twitter*, em 18.05.2015). Nessa mesma linha, cf. interessante trabalho de Lenio Streck, Por que é inconstitucional “repristinar” a separação judicial no Brasil, *Revista Consultor Jurídico — CONJUR*, de 18.11.2015 — 8h — acesso em: 18.05.2015.

77 Adotada pela Res. L. 44 (XLIV) da *Assembleia Geral das Nações Unidas* em 20.11.89, aprovada pelo DL n. 28, de 14.09.90, e promulgada pelo Dec. n. 99.710, de 21.11.90, tendo sido ratificada pelo Brasil em 24.09.90.

78 Destacamos importante previsão estabelecida pela **Lei n. 13.106/2015** que alterou referido estatuto (art. 243), para tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar

bebida alcoólica a criança ou a adolescente.

79 O Estatuto estabelece, ainda, que existirão casos **expressos** em lei, disciplinando a aplicação, excepcional, do Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nesse sentido: “Mas, a questão que ora se enfrenta diz respeito ao efeito da superveniência da maioridade penal do socioeducando no curso da medida socioeducativa que lhe foi imposta. É evidente que a aplicação do ECA estará sempre dependente da idade do agente no momento do fato (art. 104, parágrafo único). Contudo, afirmar que, atingindo a maioridade, a medida deve ser extinta é fazer ‘tábula rasa’ do Estatuto. Isso porque esta seria inócua para aqueles que cometeram atos infracionais com mais de dezessete anos. Com efeito, no limite, adotada a tese de defesa, poder-se-ia admitir medidas socioeducativas com duração de apenas um dia, hipótese, *data venia*, incompatível com os seus objetivos. (...) A manutenção do infrator, maior de dezoito e menor de vinte e um anos, sob o regime do ECA, em situações excepcionais, taxativamente enumeradas, longe de afigurar-se ilegal, tem como escopo, exatamente, protegê-lo dos rigores das sanções de natureza penal, tendo em conta a sua inimizabilidade, e reintroduzi-lo paulatinamente na vida da comunidade. O Juízo da Infância e Juventude, no caso sob exame, agiu corretamente ao determinar a progressão de regime do paciente, mantendo-o, todavia, nessa situação de semiliberdade, ainda que completados os dezoito anos, em atenção ao que dispõe o art. 121 do ECA, bem assim aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que regem o instituto da internação” (**HC 90.129**, Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.04.2007, *DJ* de 18.05.2007).

80 Nesse sentido, cf. **REsp 196.406**, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 09.03.1999.

81 Em 16.08.2010, o Min. Marco Aurélio negou seguimento ao **RE 615.261** que tratava do mesmo assunto. O fundamento, contudo, foi processual, pelo fato de não ter o Tribunal do Paraná discutido a questão à luz do art. 226 da CF.

82 Alexandre de Moraes, *Direito constitucional*, 22. ed., p. 821.

83 Nesse sentido, ver René Ariel Dotti, *Curso de direito penal*: parte geral, p. 412-413, e José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 862-863.

84 M. G. Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, 32. ed., p. 373.

85 Especialmente para as provas de MP, cf. interessante *Cartilha do Idoso*. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/Cartilha_Idoso>.

86 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 1308.

87 Cf. os seguintes artigos: 20, XI; 22, XIV; 49, XVI; 109, XI; 129, V; 176, § 1.º; 210, § 2.º; 215, § 1.º; 231; 232 e 67 do ADCT.

88 O art. 3.º, I, do *Estatuto do Índio* (Lei n. 6.001, de 19.12.1973) considera as expressões **índio** ou **silvícola** sinônimas, definindo-os como “... todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um **grupo étnico** cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional”. Por sua vez, nos termos do art. 3.º, II, **comunidade indígena** ou **grupo tribal** caracteriza-se como “... um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados”.

89 O art. **68 do ADCT** estabelece que aos **remanescentes das comunidades dos quilombos** que estejam ocupando suas terras é reconhecida a **propriedade definitiva**, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. A regulamentação do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos está prevista no **Decreto n. 4.887/2003** que está sendo discutido no STF na **ADI 3.239** e afeta cerca de 3.000 comunidades (**matéria pendente**).

90 Site da PGR: <http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/institucional/apresentacao/apresentacao_txt>. Acesso em: 16.01.2008.

91 Daniel Sarmiento, *A garantia do direito à posse dos remanescentes de quilombos antes da desapropriação*, parecer de 09.10.2006, disponível em: <http://www.cpisp.org.br/acoes/upload/arquivos/AGarantiadoDireitoaPosse_DanielSarmiento.pdf>

92 Tanto a definição do “marco temporal” como a situação do “esbulho renitente” foram enfrentadas pelo STF (e mantidas na linha do precedente firmado na PET 3.388), destacando-se (apesar de ser decisão de Turma, e não do Plenário): **RMS 29.087**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2014, 2.ª T., *DJE* de 14.10.2014; **ARE 803.462-AgR**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09.12.2014, 2.ª T., *DJE* de 12.02.2015.

93 Cf. Lei n. 5.371/67 e Dec. n. 7.778/2012.

94 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 868.

95 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 869.

96 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 870.

97 Nos termos do art. 1.º do referido Decreto Presidencial, “fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio — FUNAI, da Terra Indígena **Raposa Serra do Sol**, destinada à posse permanente dos Grupos Indígenas Ingarikó, Makuxi, Patamona, Taurepang e Wapixana, nos termos da Portaria n. 534, de 13 de abril de 2005, do Ministério da Justiça”.

98 Conforme ficou explicitado pelo Min. Barroso, “com o trânsito em julgado do acórdão embargado, todos os processos relacionados à Terra Indígena Raposa Serra do Sol deverão adotar as seguintes premissas como necessárias: (i) são válidos a Portaria/MJ n. 534/2005 e o Decreto Presidencial de 15.04.2005 **observadas as condições previstas no acórdão**; e (ii) a caracterização da área como terra indígena, para os fins dos arts. 20, XI, e 231, da Constituição torna insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante à indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF/88, art. 231, § 6.º)”. Para algumas provas nas quais a questão indígena apresenta-se com maior incidência, como as provas do **MPF**, parece interessante o conhecimento dessas **“condições previstas no acórdão”** (explicitações), estabelecidas pelo Min. Barroso. Para tanto, importante a leitura de seu voto (bastante didático e profundo) e que foi resumido no *Inf. 725/STF* e em *Notícias STF de 23.10.2013*, encontrados no site do STF <www.stf.jus.br>.

99 Nesse sentido o entendimento da Corte: “EMENTA: (...). **A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante, em sentido técnico**. Nesses termos, **os fundamentos adotados pela Corte não se estendem, de forma automática, a outros processos em que se discuta matéria similar**. Sem prejuízo disso, o acórdão embargado ostenta a **força moral e persuasiva** de uma **decisão da mais alta Corte do País**, do que decorre um **elevado ônus argumentativo** nos casos em se cogite da superação de suas razões” (Pet. 3.388 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.10.2013, Plenário, *DJE* de 04.02.2014).

100 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 4. ed., p. 870.

101 Original sem grifos. Nesse sentido, cf., ainda: HC 91.121, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.11.2007, *Inf. 487/STF*; RE 263.010, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.06.2000, *DJ* de 10.11.2000; RHC 85.737, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12.12.2006, *DJ* de 30.11.2007.

- 1 D. de A. Dallari, *Elementos da teoria geral do estado*, p. 233.
- 2 Norberto Bobbio, *A era dos direitos*, p. 72.
- 3 H. L. Wilensky, *Welfare State and equality: structural and ideological roots public expenditures*, passim, apud BOBBIO, N., MATTEUCCI, N., PASQUINO, G.; [Trad.] Carmen C. Varrialle... [et al.]; [Coord. de trad.] João Ferreira, *Dicionário de política*, v. 1, p. 416, 1. col. (verbete, “Estado do Bem-estar”).
- 4 C. F. Campilongo, Os desafios do judiciário: um enquadramento teórico, in FARIA, J. E. (org.). *Direitos humanos, direitos sociais e justiça*, p. 31-36.
- 5 *Curso de direito constitucional*, 13. ed., p. 469.
- 6 Para aprofundamento, cf. ADPF 46, Rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, j. 05.08.2009, Plenário, *DJE* de 26.02.2010.
- 7 *Comentário contextual à Constituição*, 6. ed., p. 754.

- 1 Para outras discussões, cf. cap. 8.
- 2 De acordo com o art. 20 do Tratado de Assunção, o MERCOSUL estará aberto à adesão, mediante negociação, dos demais países-membros da *Associação Latino-Americana de Integração*, cujas solicitações poderão ser examinadas pelos Estados-Partes depois de 5 anos de vigência desse Tratado. Não obstante, poderão ser consideradas antes do referido prazo as solicitações apresentadas por países-membros da *Associação Latino-Americana de Integração* que não façam parte de esquemas de integração sub-regional ou de uma associação extrarregional. A aprovação das solicitações, conforme estabelecido no citado dispositivo, será objeto de decisão unânime dos Estados-Partes.
- 3 Ilustre leitor, no momento do estudo, checar a existência de eventuais novos integrantes. Lembramos, ainda, os denominados **Estados Associados** ao MERCOSUL, que são: **Chile, Colômbia, Equador, Peru**, sendo **Guiana e Suriname** em processo de ratificação (cf. as *Decisões do Conselho Mercado Comum* de ns. 14/1996, 18/2004, 28/2004 e 11/2013, que podem ser consultadas no site da Secretaria do MERCOSUL — <www.mercosur.int>). A existência desses *Estados Associados* “justifica-se em função do compromisso do MERCOSUL com o aprofundamento do processo de integração regional e pela importância de desenvolver e intensificar as relações com os países-membros da ALADI (Associação Latino-Americana de Integração). Nesse sentido, apenas países-membros da ALADI podem associar-se ao MERCOSUL, desde que celebrem Acordos de Livre-Comércio com o bloco. Além disso, Estados que desejem se associar devem aderir ao *Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL, Bolívia e Chile* e à *Declaração Presidencial sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL*. Os Estados Associados podem participar, na qualidade de convidados, das reuniões dos órgãos da estrutura institucional do MERCOSUL para tratar temas de interesse comum, mas sem direito a voto” (texto retirado de “perguntas recentes” do site <www.mercosul.gov.br>, acesso em 20.02.2014).
- 4 Celso Bastos, *Curso de direito constitucional*, p. 163.
- 5 Disponível em: <<http://www.mercosur.int/msweb/portaI%20intermediario/pt/index.htm>>.
- 6 Todas essas informações (e citações) foram obtidas nos sites: <<http://www.mre.gov.br>> e <<http://www.mercosul.gov.br>>, de extrema valia para os candidatos que forem prestar concursos que exigem conhecimentos aprofundados sobre direito internacional. Salvo os aspectos de conhecimento geral, não nos parece o perfil dos principais concursos estaduais (Magistratura, MP, OAB etc.).

⁷ Cf. <<http://www.tprmercotur.org>>, acesso em 08.02.2014.

⁸ <http://www.tprmercotur.org/pt/sol_contr_ini_opiniones.htm>, acesso em 08.02.2014.

⁹ Cf. **Pet 4.383**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.10.2013, *DJE* de 10.10.2013.

- 1 C. A. B. de Mello, *Curso de direito administrativo*, 27. ed., p. 100.
- 2 H. L. Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, 30. ed., Malheiros, 2005, p. 419, grifamos.
- 3 Marçal Justen Filho, *Curso de direito administrativo*, Saraiva, 2005, p. 584-585, grifamos.
- 4 M. S. Z. Di Pietro, *Direito administrativo*, 18. ed., Atlas, 2005, p. 526.
- 5 **Art. 236, § 3.º, da CF/88**: “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por **delegação do Poder Público**. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de **concurso público de provas e títulos**, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 meses”.
- 6 Cf., também, **Resolução n. 80/2009 — CNJ**, que declara a **vacância** dos **serviços notariais e de registro** ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público.
- 7 O tema deverá ser aprofundado nos livros de direito administrativo, especialmente a questão relacionada à **Lei n. 12.462/2011** que instituiu o **Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)**, aplicável **exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: I** — dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); **II** — da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação — Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo — Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 — CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e **III** — de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II.
- 8 J. A. da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, 7. ed., p. 342.

- 9 Nos termos de sua ementa, “disciplina a fixação do limite remuneratório para os agentes públicos dos Poderes Legislativo e Executivo dos Estados e do Distrito Federal, determina a aplicação do disposto no art. 7.º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, às pensões derivadas dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos que se aposentarem na forma do *caput* do art. 6.º da mesma Emenda, e disciplina a forma de contribuição dos servidores portadores de doença incapacitante para o custeio da Previdência Social”.
- 10 José Afonso da Silva, *Comentário contextual à Constituição*, p. 341.
- 11 Convém lembrar que o art. 2.º da **Lei n. 11.143/2005**, ao modificar o *caput* do art. 2.º da Lei n. 8.350/91, estabeleceu que, a partir de 1.º de janeiro de 2005, a gratificação mensal de juízes eleitorais corresponderá a 18% do subsídio de juiz federal. O art. 3.º da Lei n. 11.143/2005, por sua vez, fixou que, a partir de 1.º de janeiro de 2006, a gratificação mensal de juízes eleitorais corresponderá a 16% do subsídio de juiz federal.
- 12 O voto do Ministro Peluso pode ser encontrado em *Notícias STF*, 28.02.2007 — 20h40.
- 13 Em relação ao trabalhador que se submete ao Regime Geral da Previdência, devemos lembrar que o STF, no julgamento do **ARE 664.335** (04.12.2014), com repercussão geral reconhecida, fixou **duas teses** relacionadas à utilização de equipamento de proteção individual (**EPI**): **a)** “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”; **b)** “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual — EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.
- 14 José Afonso da Silva, ao analisar o art. 6.º da EC n. 41/2003, observa que “... a lei nova, incluindo as novas emendas constitucionais, pode ressalvar direitos que ainda não tenham sido adquiridos — ou seja, pode proteger situações jurídicas subjetivas de vantagem que ainda sequer tenham alcançado a configuração de direito subjetivo. Nesse caso, a ressalva de direito gera em favor de seus titulares um direito adquirido, porque a expectativa do direito integra o patrimônio de todos aqueles que se encontrarem nas condições configuradas na regra de ressalva. Foi o caso do art. 8.º da EC 20/1998, e é o caso do art. 6.º da Emenda de que nos ocupamos (EC n. 41/03 — acrescente-se) nesta oportunidade. Aqui há uma ressalva que outorga direito novo a seus destinatários, pois, de certo modo, reconhece direito adquirido ao regime jurídico anterior”. E completa o mestre apontando

para uma projeção para o futuro de direitos previstos no regime constitucional anterior
(*Comentário contextual à Constituição*, p. 372).

Índice

Uma homenagem especial	82
Mais uma homenagem especial	84
Uma nova homenagem especial	86
Mais uma nova homenagem especial	88
Agradecimentos	92
Nota do autor à 19. ^a edição	96
Prefácio	102
Apresentação à 1. ^a edição	105
1 - (NEO)CONSTITUCIONALISMO	106
1.1. Alocação do Direito Constitucional	106
1.1.1. A classificação em “ramos do direito”	106
1.1.2. A superação da dicotomia “público-privado” — constitucionalização do direito privado	108
1.2. Constitucionalismo	109
1.2.1. Conceito	109
1.2.2. Evolução histórica	110
1.2.2.1. Constitucionalismo durante a Antiguidade	111
1.2.2.2. Constitucionalismo durante a Idade Média	111
1.2.2.3. Constitucionalismo durante a Idade Moderna	112
1.2.2.4. Constitucionalismo norte-americano	112
1.2.2.5. Constitucionalismo moderno (durante a Idade Contemporânea)	113
1.2.2.6. Constitucionalismo contemporâneo (durante a Idade Contemporânea) “antenado” com a ideia de “constitucionalismo globalizado”	113
1.2.2.7. Constitucionalismo do futuro: o que podemos esperar?	115
1.2.3. Esquematização do constitucionalismo	116
1.3. NEOCONSTITUCIONALISMO23	118
1.3.1. Aspectos iniciais	118
1.3.2. Pontos marcantes do neoconstitucionalismo	119

1.3.3. Marcos fundamentais para se chegar a um “novo direito constitucional” (neoconstitucionalismo)	121
1.4. O novo constitucionalismo democrático latino-americano. Constitucionalismo pluralista (andino ou indígena). Estado plurinacional e intercultural	124
1.5. Constitucionalismo E SOBERANIA POPULAR	127
1.5.1. Aspectos gerais	127
1.6. Questões	129
2 - CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, CLASSIFICAÇÕES, ELEMENTOS E HISTÓRICO	137
2.1. Conceito	137
2.1.1. Sentido sociológico	137
2.1.2. Sentido político	138
2.1.3. Sentido material e formal	138
2.1.4. Sentido jurídico	140
2.1.5. Sentido culturalista	142
2.1.6. Constituição aberta	143
2.1.7. Concepções da Constituição: qual o seu papel no ordenamento jurídico de um país?	144
2.1.7.1. Constituição-lei	144
2.1.7.2. Constituição-fundamento (Constituição-total)	145
2.1.7.3. Constituição-moldura	146
2.1.7.4. Constituição dúctil (Constituição maleável, suave) (“Costituzione mite” — Gustavo Zagrebelsky)	147
2.2. Crowdsourced constitution: o legado da experiência pioneira da Islândia (2011) ¹⁸	147
2.3. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA ²⁴	150
2.3.1. Aspectos iniciais	150
2.3.2. Legislação simbólica	151
2.3.2.1. Confirmação de valores sociais	152
2.3.2.2. Demonstração da capacidade de ação do Estado no tocante à solução dos problemas sociais (legislação-álibi)	153
2.3.2.3. Adiamento da solução de conflitos sociais através	

de compromissos dilatórios	
2.3.2.4. Efeitos sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica	154
2.3.3. Constitucionalização simbólica	155
2.3.4. Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico	156
2.3.5. Neoconstitucionalismo, ativismo judicial e a concretização das normas constitucionais	157
2.4. Classificação (tipologia)	158
2.4.1. Quanto à origem e a distinção entre “Constituição” e “Carta”	158
2.4.2. Quanto à forma	161
2.4.3. Quanto à extensão	162
2.4.4. Quanto ao conteúdo	164
2.4.5. Quanto ao modo de elaboração	165
2.4.6. Quanto à alterabilidade	165
2.4.7. Quanto à sistemática (critério sistemático)	168
2.4.8. Quanto à dogmática	169
2.4.9. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência)	170
2.4.10. Quanto ao sistema	171
2.4.11. Quanto à função	172
2.4.12. Quanto à origem de sua decretação: heterônomas (heteroconstituições) x autônomas (“autoconstituições” ou “homoconstituições”)	172
2.4.13. Constituições garantia, balanço e dirigente (Manoel Gonçalves Ferreira Filho)	174
2.4.14. Constituições liberais (negativas) e sociais (dirigentes) — conteúdo ideológico das Constituições (André Ramos Tavares)	175
2.4.15. Raul Machado Horta (Constituições expansivas)	175
2.4.16. A Constituição Federal brasileira de 1988	177
2.5. Elementos das Constituições	178
2.6. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS ⁸²	180
2.6.1. Constituição de 1824	180
2.6.2. Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo	

2.6.2. Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo Provisório da República	187
2.6.3. Constituição de 1891	188
2.6.4. A Revolução de 1930 — segundo Governo Provisório da República	192
2.6.5. Constituição de 1934	194
2.6.6. Constituição de 1937	198
2.6.7. Constituição de 1946	203
2.6.8. Golpe Militar de 1964	208
2.6.9. Constituição de 1967	209
2.6.10. “Constituição” de 1969 — EC n. 1, de 17.10.1969	213
2.6.11. Constituição de 1988	218
2.7. Questões	224
2.7.1. Conceito, classificação e elementos das Constituições	224
2.7.2. Histórico das Constituições brasileiras	235
3 - HERMENÊUTICA: MUTAÇÃO X REFORMA. REGRAS X PRINCÍPIOS. “DERROTABILIDADE”. POSTULADOS NORMATIVOS. CRIAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO	244
3.1. Mutações constitucionais versus reformas constitucionais	244
3.2. Regras e princípios	248
3.3. DERROTABILIDADE (defeasibility) ¹⁸	253
3.4. NORMAS DE SEGUNDO GRAU: POSTULADOS NORMATIVOS	257
3.5. Métodos de interpretação	258
3.5.1. Método jurídico ou hermenêutico clássico	258
3.5.2. Método tópico-problemático (ou método da tópica)	259
3.5.3. Método hermenêutico-concretizador	259
3.5.4. Método científico-espiritual	260
3.5.5. Método normativo-estruturante	260
3.5.6. Método da comparação constitucional	261
3.6. princípios da interpretação constitucional	261
3.6.1. Princípio da unidade da Constituição	261
3.6.2. Princípio do efeito integrador	262

3.6.4. Princípio da justeza ou da conformidade (exatidão ou correção) funcional	262
3.6.5. Princípio da concordância prática ou harmonização	263
3.6.6. Princípio da força normativa	263
3.6.7. Princípio da interpretação conforme a Constituição	264
3.6.8. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade	265
3.7. limites da interpretação constitucional	267
3.7.1. Decisões interpretativas em sentido estrito	268
3.7.1.1. Sentença interpretativa de rechaço	268
3.7.1.2. Sentença interpretativa de aceitação	269
3.7.2. Decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)	269
3.7.2.1. Sentenças aditivas (ou sentenças manipulativas de efeito aditivo). Declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo ou aditivo	269
3.7.2.2. Sentenças substitutivas (declaração de inconstitucionalidade com efeito substitutivo)	272
3.7.3. Lacuna constitucional e o “pensamento jurídico do possível” na jurisprudência do STF	274
3.7.4. Críticas ao “pan-principiologismo” e a realidade de uma inegável “Supremocracia”	276
3.8. teoria dos poderes implícitos	278
3.9. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição	280
3.10. Estrutura da constituição	285
3.10.1. Preâmbulo	285
3.10.1.1. Esquematização	285
3.10.1.2. Qual a natureza jurídica do preâmbulo? Tem ele relevância jurídica?	287
3.10.1.3. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios? Referida previsão enfraquece a laicidade do Estado brasileiro?	288
3.10.2. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	

3.10.2. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)	291
3.10.2.1. Apontamentos gerais sobre o ADCT	291
3.10.2.2. Finalidade do ADCT	291
3.10.2.3. Classificação das disposições do ADCT	292
3.10.2.4. O natural exaurimento das normas do ADCT e o seu desvirtuamento	294
3.10.2.5. Qual a natureza jurídica das disposições do ADCT?	295
3.10.2.6. As disposições do ADCT estão imunes ao poder de reforma?	296
3.11. Questões	298
3.11.1. Hermenêutica	298
3.11.2. Estrutura da Constituição	311
4 - PODER CONSTITUINTE	322
4.1. Esquema geral	322
4.2. Conceito e titularidade	322
4.3. HIATO CONSTITUCIONAL (REVOLUÇÃO — MUTAÇÃO — REFORMA — HIATO AUTORITÁRIO)	323
4.4. Poder constituinte originário (GENUÍNO OU DE 1.º GRAU)	324
4.4.1. Conceito	324
4.4.2. Uma subdivisão	325
4.4.3. Características	325
4.4.4. Poder constituinte originário formal e material	328
4.4.5. Formas de expressão	329
4.4.6. A proposta de convocação de uma “assembleia nacional constituinte exclusiva e específica” para a reforma política: aberração jurídica; violência ao sistema	329
4.5. Poder constituinte derivado (instituído, constituído, secundário, de 2.º grau ou remanescente)	331
4.5.1. Conceito e espécies ¹³	331
4.5.2. Poder constituinte derivado reformador	332
4.5.3. Poder constituinte derivado decorrente	333
4.5.3.1. Estados-Membros	333
4.5.3.2. Distrito Federal	336

4.5.3.3. Municípios: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?	337
4.5.3.4. Territórios Federais: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?	339
4.5.4. Poder constituinte derivado revisor	339
4.6. PODER CONSTITUINTE DIFUSO	342
4.7. PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL	344
4.8. Nova Constituição e ordem jurídica anterior	345
4.8.1. Recepção	345
4.8.1.1. Inconstitucionalidade superveniente?	347
4.8.1.2. Uma lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada, mas que, até o advento da nova Constituição, nunca fora objeto de controle de constitucionalidade, poderá ser recebida pela nova Constituição se com ela for compatível?	348
4.8.1.3. Características conclusivas sobre o fenômeno da recepção	350
4.8.2. Repristinação	351
4.8.3. Desconstitucionalização	352
4.8.4. Recepção material de normas constitucionais	352
4.9. poder constituinte e direito adquirido. GRAUS DE RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL: máximo, médio ou mínimo?	353
4.10. Questões	356
4.10.1. Poder constituinte	356
4.10.2. Nova Constituição e ordem jurídica anterior	365
4.10.3. Graus de retroatividade da norma constitucional	369
5 - EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS	378
5.1. Eficácia jurídica e eficácia social	378
5.2. Normas constitucionais de eficácia plena	378
5.3. Normas constitucionais de eficácia contida	380
5.4. Normas constitucionais de eficácia limitada	382
5.5. A classificação de Maria Helena Diniz	386
5.6. A classificação de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres	388

Britto	388
5.7. Normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada	389
5.8. Normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais e o gradualismo eficaz das normas constitucionais	389
5.9. EFICÁCIA E APLICABILIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO STF	391
5.10. Questões	402
6 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE	418
6.1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: DIREITO COMPARADO E SISTEMA BRASILEIRO ¹	418
6.1.1. Noções preliminares	418
6.1.2. A inconstitucionalidade das leis e a regra geral da “teoria da nulidade”. Sistema austríaco (Kelsen) versus Sistema norte-americano (Marshall). Anulabilidade versus nulidade	419
6.1.3. Flexibilização das teorias da “nulidade absoluta da lei declarada inconstitucional” e da “anulabilidade da norma inconstitucional” no direito estrangeiro (brevíssima noção)	422
6.1.3.1. Áustria	422
6.1.3.2. Estados Unidos	422
6.1.3.3. Espanha	424
6.1.3.4. Portugal	424
6.1.3.5. Alemanha	424
6.1.4. Flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro	425
6.1.4.1. A mitigação do princípio da nulidade no controle concentrado — art. 27 da Lei n. 9.868/99 e art. 11 da Lei n. 9.882/99	425
6.1.4.2. A mitigação do princípio da nulidade no controle difuso	426
6.2. BREVE ANÁLISE EVOLUTIVA DO SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ²⁷	427
6.2.1. Constituição de 1824	427

6.2.3. Constituição de 1934	428
6.2.4. Constituição de 1937	429
6.2.5. Constituição de 1946	429
6.2.6. Constituição de 1967 e EC n. 1/69	430
6.2.7. Constituição de 1988	430
6.3. ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE	432
6.3.1. Inconstitucionalidade por ação e por omissão (quadro esquemático)	432
6.3.2. Vício formal (inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato)	433
6.3.2.1. Inconstitucionalidade formal orgânica	434
6.3.2.2. Inconstitucionalidade formal propriamente dita	434
6.3.2.3. Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo	435
6.3.3. Vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário)	437
6.3.4. Vício de decoro parlamentar (?)	437
6.4. MOMENTOS DE CONTROLE	441
6.4.1. Controle prévio ou preventivo	442
6.4.1.1. Controle prévio ou preventivo realizado pelo legislativo	442
6.4.1.2. Controle prévio ou preventivo realizado pelo executivo	443
6.4.1.3. Controle prévio ou preventivo realizado pelo judiciário	444
6.4.1.4. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder judiciário e a perspectiva das “normas constitucionais interpostas” (Zagrebelsky)	447
6.4.2. Controle posterior ou repressivo	449
6.4.2.1. Controle político	449
6.4.2.2. Controle jurisdicional	450
6.4.2.3. Controle híbrido	450
6.4.2.4. Exceção à regra geral do controle jurisdicional posterior ou repressivo	450

posterior ou repressivo	450
6.4.2.4.1. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Legislativo	451
6.4.2.4.2. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Executivo	452
6.4.2.4.3. Controle posterior ou repressivo exercido pelo TCU	455
6.5. SISTEMAS E VIAS DE CONTROLE JUDICIAL	456
6.6. CONTROLE DIFUSO	458
6.6.1. Origem histórica: Marbury versus Madison, Sessão de fev. de 1803 (I, repertório de Cranch, 137-180)	458
6.6.2. Noções gerais	461
6.6.3. Controle difuso nos tribunais e a cláusula de reserva de plenário (full bench). Art. 97 da CF/88	461
6.6.3.1. Regras gerais	461
6.6.3.2. A cláusula de reserva de plenário se aplica às Turmas do STF no julgamento de RE?	464
6.6.3.3. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais?	466
6.6.3.4. A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão de juízo monocrático de primeira instância?	468
6.6.4. Efeitos da decisão	468
6.6.4.1. Para as partes	468
6.6.4.2. Para terceiros (art. 52, X)	470
6.6.4.2.1. Procedimento	470
6.6.4.2.2. Amplitude do art. 52, X	471
6.6.4.2.3. A expressão “no todo ou em parte”	472
6.6.4.2.4. Efeitos propriamente ditos	472
6.6.4.2.5. O Senado é obrigado a suspender os efeitos?	473
6.6.5. Teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso: análise crítica — abstrativização do controle difuso? — tendência para uma maior expansividade das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias individuais. Limitação do cabimento da reclamação. ⁸⁵ Perspectivas do controle incidental em	474

6.6.5.1. Abstrativização do controle difuso?	475
6.6.5.2. Eficácia expansiva das decisões. Objetivação do recurso extraordinário. Limites à reclamação constitucional. Inconstitucionalidades no CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)	481
6.6.5.3. Controle incidental em controle concentrado abstrato e o seu efeito “erga omnes” — eficácia da decisão do STF	490
6.6.6. Controle difuso em sede de ação civil pública	494
6.7. CONTROLE CONCENTRADO	495
6.7.1. ADI genérica	496
6.7.1.1. Conceito (ADI genérica)	496
6.7.1.2. Objeto (ADI genérica)	497
6.7.1.2.1. Leis	497
6.7.1.2.2. Atos normativos	497
6.7.1.2.3. Súmulas?	498
6.7.1.2.4. Emendas constitucionais?	499
6.7.1.2.5. Medidas provisórias?	500
6.7.1.2.6. Regulamentos subordinados ou de execução e decretos? Inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua	503
6.7.1.2.7. Tratados internacionais	505
6.7.1.2.8. Normas constitucionais originárias	508
6.7.1.2.9. O fenômeno da recepção	509
6.7.1.2.10. Atos estatais de efeitos concretos e atos estatais de efeitos concretos editados sob a forma de lei (exclusivamente formal)	510
6.7.1.2.11. Ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida	512
6.7.1.2.12. Lei revogada ou que tenha perdido a sua vigência após a propositura da ADI. O caso particular da fraude processual. Novas perspectivas: singularidades do caso (não prejudicialidade)	513
6.7.1.2.13. Alteração do parâmetro constitucional invocado. Novo precedente na linha de não ocorrência de prejuízo desde que analisada a situação concreta. Superação da jurisprudência da	515

ocorrência de prejuízo desde que analisada a situação concreta. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria na hipótese de inadmitida constitucionalidade superveniente	515
6.7.1.2.14. Divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo	518
6.7.1.2.15. Respostas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral	518
6.7.1.2.16. Leis orçamentárias?	518
6.7.1.2.17. Resoluções do CNJ e do CNMP	520
6.7.1.2.18. Ato administrativo normativo genérico (ADI 3.202 — agravo regimental em processo administrativo)	520
6.7.1.2.19. ADI “versus” políticas públicas? A teoria da “reserva do possível”	521
6.7.1.3. Elementos essenciais do controle de constitucionalidade: a) elemento conceitual (o conceito de “bloco de constitucionalidade”); b) elemento temporal	522
6.7.1.4. Teoria da transcendência dos motivos determinantes (efeitos irradiantes ou transbordantes?) (“Ratio decidendi” — “holding” versus “obiter dictum” — “dictum”)	524
6.7.1.5. Teoria da inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”, ou inconstitucionalidade consequencial, ou inconstitucionalidade consequente ou derivada, ou “inconstitucionalidade por reverberação normativa”	527
6.7.1.6. Lei “ainda constitucional”, ou “inconstitucionalidade progressiva”, ou “declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade”	529
6.7.1.6.1. A instituição da Defensoria Pública pela CF/88 e a sua potencialização pela EC n. 80/2014	529
6.7.1.6.1.1. A questão do “prazo em dobro” para a Defensoria Pública no processo penal — rejeição de inconstitucionalidade “rebus sic stantibus”	530
6.7.1.6.1.2. Ação civil “ex delicto” ajuizada pelo MP	

trânsito para revogação por não recepção)	
6.7.1.6.2. Procedimento de aprovação das medidas provisórias: apreciação pela comissão mista nos termos do art. 62, § 9.º, da CF/88. Arts. 5.º, “caput”, e 6.º, “caput”, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN	534
6.7.1.7. “Inconstitucionalidade circunstancial”	536
6.7.1.8. O efeito vinculante para o Legislativo e o inconcebível fenômeno da “fossilização da Constituição”	538
6.7.1.9. Município putativo. Princípio da reserva do impossível. Princípio da continuidade do Estado. Princípio federativo. Princípio da segurança jurídica. Princípio da confiança (Karl Larenz). Princípio da força normativa dos fatos (Georg Jellinek). Princípio da situação excepcional consolidada — ADI 2.240/BA — voto do Min. Eros Grau. Voto do Min. Gilmar Mendes — Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Efeito prospectivo. Possibilidade inédita do fenômeno da constitucionalidade superveniente. Dogma da nulidade da lei e garantia da segurança jurídica	539
6.7.1.10. “Princípio” da proibição do “atalhamento constitucional” e do “desvio de poder constituinte” (utilização de meio aparentemente legal buscando atingir finalidade ilícita)	545
6.7.1.11. Inconstitucionalidade “chapada”, “enlouquecida”, “desvairada”	546
6.7.1.12. Início da eficácia da decisão que reconhece a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de lei em processo objetivo de controle abstrato	546
6.7.1.13. Competência (ADI genérica)	548
6.7.1.13.1. Lei ou ato normativo federal ou estadual em face da CF	548
6.7.1.13.2. Lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da CE	549
6.7.1.13.3. Lei ou ato normativo municipal em face da CF	549
6.7.1.13.4. Lei ou ato normativo distrital em face da CF/88	550

CF/88	
6.7.1.13.5. Lei ou ato normativo distrital em face da Lei Orgânica Distrital	551
6.7.1.13.6. Lei municipal em face da lei orgânica do Município	553
6.7.1.14. Legitimidade (ADI genérica)	553
6.7.1.15. Procedimento e características marcantes do processo objetivo (ADI genérica)	557
6.7.1.16. A figura do “amicus curiae” (ADI e demais ações)	565
6.7.1.16.1. Regras gerais	565
6.7.1.16.2. É possível a admissão do “amicus curiae” na ADC?	569
6.7.1.16.3. Cabe “amicus curiae” na ADPF?	571
6.7.1.16.4. Cabe “amicus curiae” na ADO?	572
6.7.1.16.5. Cabe “amicus curiae” na IF (representação interventiva)?	572
6.7.1.16.6. Outras hipóteses de cabimento	573
6.7.1.16.7. Parlamentar pode ser admitido no processo como “amicus curiae”? (Novidade mais ampla introduzida pelo CPC/2015 — Lei n. 13.105/2015)	574
6.7.1.16.8. Natureza jurídica do “amicus curiae”	575
6.7.1.16.9. “Amicus curiae” pode interpor recurso? Particularidades do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)	576
6.7.1.17. Efeitos da decisão (ADI genérica)	578
6.7.1.17.1. Princípio da parcelaridade	581
6.7.1.17.2. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto	582
6.7.1.17.3. Efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Necessidade de impugnação de todo o “complexo normativo”	582
6.7.1.17.4. Efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade ¹⁹²	585
6.7.1.17.4.1. Coisa julgada inconstitucional. S. 343/STF. Rescisória (art. 485, V, CPC/73)	585

22.10.2014). CPC/73 e CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015)	589
6.7.1.17.4.3. Arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73: “embargos rescisórios”. Como ficou no Novo CPC/2015 (arts. 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5.º a 8.º)?	593
6.7.1.17.4.4. Aspectos conclusivos: efeito da decisão no plano normativo (“Normebene”) e no plano do ato singular (“Einzelaktebene”) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão (interessante tendência apontada pelo Min. Gilmar Mendes). Perspectiva introduzida pelo CPC/2015	600
6.7.1.17.5. Pedido de cautelar (ADI genérica)	604
6.7.1.18. Reclamação para a garantia da autoridade da decisão do STF: paradigma de ordem objetiva (ADI genérica e súmula vinculante)	605
6.7.1.18.1. Regras gerais	605
6.7.1.18.2. Natureza jurídica do instituto da reclamação	608
6.7.2. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)	609
6.7.2.1. Conceito (ADC)	609
6.7.2.2. Objeto (ADC)	610
6.7.2.3. Competência (ADC)	611
6.7.2.4. Legitimidade (ADC)	611
6.7.2.5. Procedimento (ADC)	611
6.7.2.6. Efeitos da decisão (ADC)	614
6.7.2.7. Medida cautelar (ADC)	614
6.7.3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)	615
6.7.3.1. Localização (ADPF)	615
6.7.3.2. Objeto — hipóteses de cabimento (ADPF)	616
6.7.3.3. Preceito fundamental — conceito (ADPF)	617
6.7.3.4. Competência (ADPF)	618
6.7.3.5. Legitimidade (ADPF)	619
6.7.3.6. Procedimento (ADPF). Particularidades do princípio da subsidiariedade	619

6.7.3.6. Procedimento (ADPF). Particularidades do princípio da subsidiariedade	619
6.7.3.7. Efeitos da decisão (ADPF)	622
6.7.3.8. O parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99 é inconstitucional (arguição incidental)?	623
6.7.3.9. Pedido de medida liminar (ADPF)	624
6.7.3.10. ADPF pode ser conhecida como ADI? Se sim, o princípio da fungibilidade teria natureza ambivalente? Ou seja, ADI poderia ser conhecida como ADPF?	625
6.7.4. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)	627
6.7.4.1. Conceito (ADO)	628
6.7.4.2. Espécies de omissão	628
6.7.4.3. Objeto (ADO)	629
6.7.4.4. Competência (ADO)	631
6.7.4.5. Legitimidade (ADO)	631
6.7.4.6. Natureza jurídica dos legitimados (ADO)	631
6.7.4.7. Procedimento (ADO)	631
6.7.4.8. Medida cautelar (ADO)	633
6.7.4.9. Efeitos da decisão (ADO)	634
6.7.4.10. A atual jurisprudência do STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO?	640
6.7.5. Representação interventiva (IF)	641
6.7.5.1. Conceito (IF)	641
6.7.5.2. Representação interventiva federal (ADI interventiva federal)	643
6.7.5.2.1. Objeto (IF)	644
6.7.5.2.2. Princípios sensíveis	647
6.7.5.2.3. Competência (IF)	648
6.7.5.2.4. Legitimidade (IF)	648
6.7.5.2.5. Procedimento (IF)	649
6.7.5.2.6. Medida liminar (IF)	652
6.7.5.2.7. Representação interventiva no caso de recusa à execução de lei federal	653
6.7.5.3. Representação interventiva estadual (ADI	654

6.8. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS ESTADOS-MEMBROS	658
6.8.1. Regras gerais	658
6.8.2. Objeto	658
6.8.3. Competência	659
6.8.4. Legitimados	659
6.8.5. Parâmetro de controle	662
6.8.5.1. Regras gerais	662
6.8.5.2. A parametricidade das cláusulas constitucionais estaduais, de caráter remissivo, para fins de controle concentrado, no âmbito do TJ local	664
6.8.5.3. “Simultaneus processus”	664
6.8.6. A utilização do recurso extraordinário no controle concentrado e em abstrato estadual	666
6.9. QUADRO COMPARATIVO DO SISTEMA JURISDICIONAL MISTO DE CONTROLE POSTERIOR OU REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL	668
6.10. QUESTÕES	674
6.10.1. Conceitos gerais	674
6.10.2. Legitimidade	679
6.10.3. Procedimento	681
6.10.4. Efeitos da decisão	685
6.10.5. Outras questões	688
7 - DIVISÃO ESPACIAL DO PODER — ORGANIZAÇÃO DO ESTADO	709
7.1. Noções preliminares	709
7.1.1. Elementos integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado	709
7.1.2. Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado	710
7.2. Estado unitário	710
7.2.1. Estado unitário puro	710
7.2.2. Estado unitário descentralizado administrativamente	711
7.2.3. Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente	711

politicamente	
7.3. Federação	711
7.3.1. Histórico	711
7.3.2. Tipologias do Federalismo	713
7.3.2.1. Federalismo por agregação ou por desagregação (segregação)	713
7.3.2.2. Federalismo dual ou cooperativo	714
7.3.2.3. Federalismo simétrico ou assimétrico	715
7.3.2.4. Federalismo orgânico	715
7.3.2.5. Federalismo de integração	716
7.3.2.6. Federalismo equilíbrio	716
7.3.2.7. Federalismo de segundo grau	717
7.3.3. Características da Federação	717
7.3.4. Federação brasileira	718
7.3.4.1. Breve histórico	718
7.3.4.2. Federação na CF/88 e princípios fundamentais ¹⁷	719
7.3.4.2.1. Composição e sistematização conceitual	719
7.3.4.2.2. Fundamentos da República Federativa do Brasil	720
7.3.4.2.3. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil	720
7.3.4.2.3.1. Art. 3.º, CF/88	721
7.3.4.2.3.2. As alterações introduzidas pela EC n. 87/2015 em relação ao ICMS no contexto dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil	721
7.3.4.2.4. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais	726
7.3.4.2.5. Idioma oficial e símbolos da República Federativa do Brasil	727
7.3.4.2.6. Vedações constitucionais impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios	730
7.4. União Federal	730
7.4.1. Capital Federal	731
7.4.2. Bens da União	734

7.4.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)	737
7.4.3.2. Competência legislativa	738
7.4.3.3. Competência para legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação — discussão em relação à EC n. 85/2015	740
7.4.3.4. Legislação sobre o meio ambiente e competência municipal. O caso particular da queima da palha da cana-de-açúcar (RE 586.224)	741
7.4.4. Regiões administrativas ou de desenvolvimento	743
7.5. Estados-Membros	745
7.5.1. Formação dos Estados-Membros	746
7.5.1.1. Regra geral	746
7.5.1.2. Aspectos específicos e procedimentais	747
7.5.1.3. E qual deve ser o procedimento no caso de criação de um novo Estado?	750
7.5.1.4. Fusão	751
7.5.1.5. Cisão	752
7.5.1.6. Desmembramento	752
7.5.2. Bens dos Estados-Membros	754
7.5.3. Competências dos Estados-Membros	754
7.5.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)	754
7.5.3.2. Competência legislativa	754
7.5.4. Exploração dos serviços locais de gás canalizado	756
7.5.5. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões	756
7.5.5.1. Aspectos gerais	756
7.5.5.2. Conceito	757
7.5.5.3. O que aconteceu com as regiões metropolitanas instituídas antes da nova Constituição de 1988?	759
7.5.5.4. Caráter compulsório da participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões	759
7.5.5.5. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a	

integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal que deverá ser preservada. Não se admite a simples transferência de competências exclusivamente para o Estado-Membro. A gestão deverá ser compartilhada	760
7.5.5.6. “Estatuto da Metrópole” — Lei n. 13.089/2015	761
7.5.5.7. Qual a natureza jurídica das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões criadas por lei complementar estadual?	763
7.6. Municípios	764
7.6.1. Formação dos Municípios	765
7.6.2. Competências dos Municípios	769
7.6.2.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)	769
7.6.2.2. Competências legislativas	769
7.6.2.3. Competência municipal para legislar sobre meio ambiente (RE 586.224)	770
7.7. Distrito Federal	771
7.7.1. Histórico	771
7.7.2. Distrito Federal como unidade federada	772
7.7.3. Outras características importantes	772
7.7.4. Competências do Distrito Federal	774
7.7.4.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)	774
7.7.4.2. Competências legislativas	774
7.8. Territórios Federais	775
7.8.1. Histórico	775
7.8.2. Natureza jurídica	776
7.8.3. Ainda existem territórios no Brasil?	777
7.8.4. Mas, afinal de contas, o que é Fernando de Noronha?	777
7.8.5. Apesar de não existirem, podem vir a ser criados novos territórios?	778
7.8.6. Outras características importantes	779
7.9. MODELOS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS	780
7.9.1. Modelo clássico e modelo moderno	781

7.9.1.2. Modelo moderno	781
7.9.2. Modelo horizontal e modelo vertical	782
7.9.2.1. Modelo horizontal	782
7.9.2.2. Modelo vertical	782
7.10. QUADRO ILUSTRATIVO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL — ALGUNS PRECEDENTES DO STF	783
7.11. AMIANTO, TABACO E OUTDOOR ⁶⁵	808
7.11.1. Amianto	809
7.11.2. Tabaco	812
7.11.3. Outdoor — “Lei Cidade Limpa”	814
7.12. Intervenção	814
7.12.1. Intervenção federal	815
7.12.1.1. Hipóteses de intervenção federal	815
7.12.1.2. Espécies de intervenção federal	816
7.12.1.3. Decretação e execução da intervenção federal	818
7.12.1.4. Controle exercido pelo Congresso Nacional	818
7.12.1.4.1. Hipóteses em que o controle exercido pelo Congresso Nacional é dispensado	818
7.12.1.5. Afastamento das autoridades envolvidas	819
7.12.2. Intervenção estadual	819
7.12.2.1. Hipóteses de intervenção estadual e intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais	819
7.12.2.2. Decretação e execução da intervenção estadual	820
7.12.2.3. Controle exercido pelo legislativo	820
7.12.2.3.1. Hipóteses em que o controle exercido pela Assembleia Legislativa é dispensado	820
7.12.2.4. Afastamento das autoridades envolvidas	821
7.12.2.5. Súmula 637 do STF	821
7.13. Questões	821
7.13.1. Federação: aspectos conceituais	821
7.13.2. Federação: intervenção	826
7.13.3. Federação: competência	829
8 - SEPARAÇÃO DE “PODERES” — TEORIA	

8 - SEPARAÇÃO DE “PODERES” — TEORIA GERAL	842
8.1. Noções introdutórias	842
8.1.1. Aristóteles: identificação das funções do Estado	842
8.1.2. Montesquieu: correspondência entre a divisão funcional e a divisão orgânica	843
8.1.3. E qual seria a finalidade da separação dos poderes?	844
8.2. funções típicas e atípicas	846
8.3. Impropriedade da expressão “tripartição de Poderes”	848
8.4. A independência dos Poderes e a indelegabilidade de atribuições	850
8.5. Questões	853
9 - PODER LEGISLATIVO	861
9.1. Estrutura do poder legislativo	861
9.1.1. Estrutura do Poder Legislativo federal	861
9.1.2. Estrutura do Poder Legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais	862
9.1.2.1. Estrutura do Poder Legislativo estadual	862
9.1.2.2. Estrutura do poder legislativo municipal	864
9.1.2.3. Estrutura do poder legislativo distrital	868
9.1.2.4. Estrutura do poder legislativo dos Territórios Federais	868
9.2. Atribuições do Congresso Nacional	869
9.3. Câmara dos Deputados	871
9.3.1. Aspectos fundamentais	871
9.3.2. Requisitos para a candidatura dos Deputados Federais	873
9.3.3. Competências privativas da Câmara dos Deputados	873
9.4. Senado Federal	875
9.4.1. Aspectos fundamentais	875
9.4.2. Requisitos para a candidatura dos Senadores	876
9.4.3. Competências privativas do Senado Federal	876
9.5. Quadro comparativo e deliberações	878
9.6. REMUNERAÇÃO DOS PARLAMENTARES	881
9.6.1. Subsídio mensal	881

9.7. Das reuniões	886
9.7.1. Sessão legislativa ordinária	886
9.7.2. Hipóteses de convocação extraordinária	887
9.7.3. Reunião em sessão conjunta	889
9.7.4. Sessão preparatória e Mesas Diretoras	890
9.8. Das comissões parlamentares	891
9.8.1. Comissão temática ou em razão da matéria (permanentes)	891
9.8.2. Comissão especial ou temporária	894
9.8.3. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)	894
9.8.3.1. Regras gerais	894
9.8.3.2. Criação	895
9.8.3.3. Direito público subjetivo das minorias	895
9.8.3.4. Objeto	897
9.8.3.5. Prazo	898
9.8.3.6. Poderes	899
9.8.3.7. O princípio da separação de “poderes” e a impossibilidade de a CPI investigar atos de conteúdo jurisdicional	903
9.8.3.8. Postulado de reserva constitucional de jurisdição	903
9.8.3.9. Postulado da colegialidade	905
9.8.3.10. Motivação	906
9.8.3.11. Conclusões	906
9.8.3.12. Competência originária do STF	908
9.8.3.13. A regra da prejudicialidade	908
9.8.3.14. CPIs estaduais e quebra do sigilo bancário	909
9.8.3.15. CPIs distritais	916
9.8.3.16. CPIs municipais	916
9.8.4. Comissão mista	918
9.8.5. Comissão representativa	919
9.9. Imunidades parlamentares	919
9.9.1. Aspectos introdutórios	919
9.9.2. Imunidade parlamentar federal	920
9.9.2.1. Imunidade material ou inviolabilidade	921

parlamentar (art. 53, "caput")	921
9.9.2.2. Imunidade formal ou processual	922
9.9.2.2.1. Imunidade formal ou processual para a prisão (art. 53, § 2.º). Perspectivas em razão do julgamento da AP 470 — “mensalão”	922
9.9.2.2.2. Imunidade formal ou processual para o processo (art. 53, §§ 3.º a 5.º)	927
9.9.2.3. Prerrogativa de foro (“foro privilegiado”) (art. 53, § 1.º)	929
9.9.2.3.1. Regra geral para os parlamentares federais — STF. Cessado o mandato parlamentar, por regra (salvo exceção comentada nos itens seguintes), deixa de existir competência originária da Corte para o julgamento de ação penal contra membro do Congresso Nacional	930
9.9.2.3.2. Renúncia ao mandato. Caso “Gulliver”. “Ciranda dos processos”. “Valsa processual”. Perspectivas de resgate da S. 394/STF (AP 333)	933
9.9.2.3.3. Renúncia ao mandato. Manutenção da competência do STF. Abuso de direito. Fraude processual inaceitável (AP 396)	935
9.9.2.3.4. Necessidade de definição de critério objetivo para a caracterização da hipótese de fraude processual e abuso de direito a manter a competência do STF em caso de renúncia ao mandato. Renúncia abusiva. Renúncia manipulativa. Debate (AP 536)	937
9.9.2.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento	939
9.9.2.5. Outras garantias	940
9.9.2.6. As imunidades parlamentares podem ser renunciadas?	941
9.9.2.7. As imunidades parlamentares estendem-se aos suplentes?	942
9.9.3. Parlamentares estaduais	943
9.9.4. Parlamentares municipais	943
9.10. Incompatibilidades e impedimentos dos parlamentares	

federais

9.11. Perda do mandato do Deputado ou Senador	945
9.11.1. Hipóteses de perda do mandato e suas peculiaridades	945
9.11.2. Cassação ⁴⁷ x extinção do mandato	947
9.11.3. Votação aberta na hipótese de cassação do mandato: aprovação da “PEC do voto aberto” (EC n. 76/2013). Avanço democrático	948
9.11.4. A perda do mandato parlamentar em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado e a interpretação fixada pelo STF no julgamento da AP 470 (“mensalão”), bem como da AP 565 (art. 15, III, x art. 55, §§ 2.º e 3.º). O caso concreto da AP 39650	949
9.11.5. É possível a renúncia do cargo por parlamentar submetido a processo que vise ou possa levá-lo à perda do mandato?	954
9.12. Hipóteses em que não haverá a perda do mandato do Deputado OU SENADOR E OUTRAS REGRAS	954
9.13. Processo legislativo	956
9.13.1. Considerações introdutórias	956
9.13.2. Esquema do processo legislativo das leis ordinárias e complementares	957
9.13.3. Fase de iniciativa	958
9.13.3.1. Regra geral para a iniciativa	958
9.13.3.2. Iniciativa concorrente	959
9.13.3.3. Iniciativa “privativa” (reservada ou exclusiva)	959
9.13.3.3.1. Iniciativa reservada ao Presidente da República	959
9.13.3.3.2. Iniciativa reservada aos Governadores dos Estados e do DF e aos Prefeitos — simetria com o modelo federal	960
9.13.3.3.3. Iniciativa reservada do Judiciário	961
9.13.3.3.4. Iniciativa reservada aos Tribunais de Contas	962
9.13.3.3.5. Assuntos exclusivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal	963
9.13.3.3.6. Podemos falar em iniciativa reservada de matéria tributária?	963

matéria tributária?	963
9.13.3.3.7. Iniciativa do processo legislativo de matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos Anuais	964
9.13.3.3.8. Pode o legitimado exclusivo ser compelido a deflagrar processo legislativo?	965
9.13.3.3.9. Cabe emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada?	965
9.13.3.3.10. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas em relação às normas fruto da manifestação do poder constituinte derivado decorrente?	967
9.13.3.3.11. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas, enquanto limites, pelo poder constituinte derivado reformador (PEC)?	968
9.13.3.3.12. Sanção presidencial convalida vício de iniciativa?	968
9.13.3.4. Iniciativa popular	970
9.13.3.4.1. Aspectos gerais	970
9.13.3.4.2. Existe algum exemplo de lei fruto de iniciativa popular?	972
9.13.3.4.3. Conclusões iniciais	975
9.13.3.4.4. Iniciativa popular de “PEC”?	976
9.13.3.4.5. Cabe iniciativa popular de matérias reservadas à iniciativa exclusiva de outros titulares?	981
9.13.3.4.6. Iniciativa popular e as espécies normativas: esquematização	982
9.13.3.4.7. Iniciativa popular em âmbito estadual e municipal	983
9.13.3.5. Iniciativa conjunta: ainda persiste, tendo em vista a Reforma da Previdência (EC n. 41/2003)?	983
9.13.3.6. Iniciativa para fixação do subsídio dos Ministros do STF — teto do funcionalismo — art. 48, XV, c/c o art. 96, II, “b”	984
9.13.3.7. Algumas peculiaridades a serem observadas	988

9.13.3.7.2. Proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67 — princípio da irrepetibilidade)	989
9.13.3.7.3. Iniciativa parlamentar ou extraparlamentar	991
9.13.4. Fase constitutiva	991
9.13.4.1. Deliberação parlamentar — discussão e votação	992
9.13.4.1.1. O projeto começa na Câmara ou no Senado?	992
9.13.4.1.2. Apreciação pelas Comissões	992
9.13.4.1.3. Processos de votação	994
9.13.4.1.4. A Casa revisora	996
9.13.4.1.5. Espécies de emendas	997
9.13.4.1.6. Algumas outras regras fundamentais	998
9.13.4.2. Deliberação executiva — sanção e veto	999
9.13.4.2.1. Sanção	999
9.13.4.2.2. Regras gerais sobre o veto	1001
9.13.4.2.3. Os vetos devem ser apreciados na ordem cronológica de sua comunicação ao Congresso Nacional? (MS 31.816 — "royalties" do pré-sal)	1002
9.13.4.2.4. Procedimento de apreciação dos vetos presidenciais (Res. n. 1/2015-CN)	1005
9.13.4.2.5. Regras específicas sobre o veto	1006
9.13.5. Fase complementar — promulgação e publicação	1007
9.13.5.1. Promulgação	1007
9.13.5.2. Publicação	1008
9.14. Espécies normativas	1009
9.14.1. Emenda constitucional	1010
9.14.1.1. Limitações formais ou procedimentais (art. 60, I, II, III, e §§ 2.º, 3.º e 5.º)	1011
9.14.1.2. Limitações circunstanciais (art. 60, § 1.º)	1013
9.14.1.3. Limitações materiais (art. 60, § 4.º)	1013
9.14.1.4. Limitações temporais?	1017
9.14.1.5. Limitações implícitas	1018
9.14.1.6. Tratados e convenções internacionais sobre	

9.14.1.6. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e a sua equivalência com as emendas constitucionais — EC n. 45/2004	1019
9.14.2. Lei complementar e lei ordinária	1019
9.14.2.1. Semelhanças	1019
9.14.2.2. Diferenças	1020
9.14.2.2.1. Aspecto material	1020
9.14.2.2.2. Aspecto formal	1020
9.14.2.3. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária?	1023
9.14.3. Lei delegada	1024
9.14.4. Medida provisória	1027
9.14.4.1. Aspectos iniciais	1027
9.14.4.2. O processo de criação das medidas provisórias de acordo com a EC n. 32/2001	1029
9.14.4.3. Parecer prévio pela comissão mista e a inconstitucionalidade dos arts. 5.º, "caput", e 6.º, "caput", e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN	1032
9.14.4.4. Medidas a serem adotadas pelo Congresso Nacional	1034
9.14.4.4.1. Aprovação sem alteração	1035
9.14.4.4.2. Aprovação com alteração	1035
9.14.4.4.3. Não apreciação (rejeição tácita)	1036
9.14.4.4.4. Rejeição expressa	1038
9.14.4.5. Impacto da medida provisória sobre o ordenamento jurídico	1039
9.14.4.6. Pode o Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória já editada?	1039
9.14.4.7. Limitação material à edição de medidas provisórias, de acordo com a EC n. 32/2001	1040
9.14.4.8. O que acontecerá com as medidas provisórias editadas em data anterior à EC n. 32/2001?	1044
9.14.4.9. Um alerta	1045
9.14.5. Decreto legislativo	1046
9.14.5.1. Aspectos gerais	1046

tratados internacionais e a novidade trazida pela EC n. 45/2004	1046
9.14.5.2.1. Tratados e convenções internacionais gerais	1046
9.14.5.2.2. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (EC n. 45/2004)	1050
9.14.5.2.3. A “supralegalidade” dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos	1054
9.14.6. Resolução	1057
9.14.7. Quadro comparativo das espécies normativas	1059
9.15. Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e o Tribunal de Contas	1060
9.15.1. Tribunal de Contas da União	1061
9.15.1.1. Composição e características	1061
9.15.1.2. Atribuições constitucionais do TCU	1063
9.15.1.3. “Apreciar as contas” x “julgar as contas” (art. 71, I e II)	1064
9.15.1.4. Exercício do controle difuso de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas	1066
9.15.1.5. Sustação de “atos” e “contratos” administrativos pelo Tribunal de Contas	1066
9.15.1.6. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas?	1068
9.15.1.7. É necessária a observância do devido processo legal em processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas?	1068
9.15.1.8. O Tribunal de Contas pode exigir, por si, a quebra de sigilo bancário?	1069
9.15.1.9. Teoria dos poderes implícitos e as atribuições do Tribunal de Contas — possibilidade de concessão de medidas cautelares para assegurar o exercício de suas atribuições	1070
9.15.1.10. Situação jurídica acobertada pela autoridade da coisa julgada pode ser desconstituída por decisão ou ato do Tribunal de Contas?	1071
9.15.1.11. Decisões do Tribunal de Contas com eficácia	

9.15.1.11. Decisões do Tribunal de Contas com eficácia de título executivo	1072
9.15.1.12. Ao decidir, cabe ao Tribunal de Contas manter o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia?	1073
9.15.1.13. Ministros do Tribunal de Contas da União	1077
9.15.2. Distinção entre a atuação do TCU e da CGU: inexistência de invasão de atribuições. Auxílio no controle externo (TCU) x controle interno (CGU) — perfeita convivência	1078
9.15.3. Tribunais de Contas Estaduais e Tribunal de Contas do Distrito Federal	1080
9.15.4. Tribunais de Contas Municipais	1082
9.15.5. Ministério Público Especial (art. 130)	1084
9.16. Questões	1086
9.16.1. Do Poder Legislativo — Aspectos gerais (estrutura, atribuições, reuniões, comissões, imunidades, incompatibilidades e impedimentos, perda do mandato)	1086
9.16.2. Tribunal de Contas	1092
9.16.3. Processo legislativo	1096
9.16.4. Espécies normativas	1101
10 - PODER EXECUTIVO	1113
10.1. Notas introdutórias	1113
10.2. Presidencialismo versus parlamentarismo	1113
10.3. Executivo monocrático, colegial, diretorial e dual — conceito	1115
10.4. O poder executivo na CF/88	1115
10.4.1. O exercício do Poder Executivo no Brasil	1115
10.4.1.1. Âmbito federal	1115
10.4.1.2. Âmbito estadual	1116
10.4.1.3. Âmbito distrital	1116
10.4.1.4. Âmbito municipal	1117
10.4.1.5. Âmbito dos Territórios Federais	1117
10.4.2. Atribuições conferidas ao Presidente da República	1117
10.4.2.1. Regras gerais do art. 84 da CF/88	1117
10.4.2.2. Regras específicas decorrentes do art. 84 da	1120

10.4.2.3. O poder regulamentar e a realidade dos denominados “decretos autônomos”	1122
10.4.3. Condições de elegibilidade	1124
10.4.4. Processo eleitoral	1124
10.4.5. Posse e mandato	1125
10.4.6. Impedimento e vacância dos cargos	1125
10.4.6.1. Sucessor e substituto natural do Presidente da República: Vice-Presidente	1125
10.4.6.2. Substitutos eventuais ou legais	1126
10.4.6.3. Mandato-tampão: eleição direta e indireta (art. 81)	1129
10.4.6.4. Ausência do País do Presidente e do Vice-Presidente da República e licença do Congresso Nacional	1131
10.4.7. Ministros de Estado	1133
10.4.7.1. Características gerais e requisitos de investidura no cargo	1133
10.4.7.2. Atribuições dos Ministros de Estado	1133
10.4.7.3. Poderão os Ministros de Estado receber delegação para exercer matéria de competência privativa do Presidente da República?	1134
10.4.7.4. Responsabilidade e juízo competente para processar e julgar os Ministros de Estado. A análise do controle político pela Câmara dos Deputados (art. 51, I)	1134
10.4.8. Conselho da República	1136
10.4.9. Conselho de Defesa Nacional	1137
10.4.10. Crimes de responsabilidade	1137
10.4.10.1. Notas introdutórias e natureza jurídica	1138
10.4.10.2. Procedimento	1139
10.4.10.2.1. Câmara dos Deputados	1140
10.4.10.2.2. Senado Federal	1141
10.4.10.3. Controle judicial?	1142
10.4.11. Crimes comuns	1142
10.4.11.1. Conceito e procedimento	1142
10.4.11.2. Imunidade presidencial (irresponsabilidade penal relativa)	1143

10.4.12. Prisão	1144
10.4.13. A imunidade formal relativa à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa podem ser estendidas aos demais chefes do Poder Executivo por leis dos respectivos entes federativos?	1144
10.4.14. Outras regras importantes sobre os demais Chefes do Poder Executivo	1146
10.4.14.1. Os demais entes federativos podem dispor sobre crime de responsabilidade definindo o órgão julgador por ato legislativo próprio?	1146
10.4.14.2. Os demais entes federativos podem estabelecer a licença prévia pelo legislativo local para o julgamento dos Chefes do Executivo?	1147
10.4.15. Sistematização da competência para julgamento das autoridades pela prática de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade	1150
10.4.15.1. Prefeitos Municipais	1153
10.4.15.2. Vereadores Municipais	1157
10.4.15.3. A inconstitucionalidade das regras trazidas pela Lei n. 10.628/2002 em relação à “perpetuatio jurisdictionis” e ao “inusitado foro cível por prerrogativa de função em lei processual penal”	1158
10.4.15.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento	1160
10.4.15.5. Distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na CF — Rcl 2.138-6-DF	1164
10.4.15.6. Responsabilidade fiscal e as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas — LC n. 101/2000 e Lei n. 10.028/2000	1166
10.5. Questões	1168
11 - PODER JUDICIÁRIO	1180
11.1. FUNÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO	1180
11.2. Algumas características da jurisdição	1180
11.3. Reforma do Poder Judiciário — EC n. 45/20047	1181

11.3.2. Principais alterações	1184
11.3.3. Principais ações diretas e decisões do STF em relação às novidades introduzidas pela EC n. 45/2004 (ordem cronológica de propositura)	1190
11.4. Estatuto da Magistratura	1193
11.4.1. Disposições gerais	1193
11.4.2. EC n. 88/2015 e ADI 5.316 (“PEC da Bengala”)	1201
11.5. Garantias do Judiciário	1205
11.5.1. Garantias institucionais do Judiciário	1206
11.5.1.1. Garantias de autonomia orgânico-administrativa	1206
11.5.1.2. Garantias de autonomia financeira	1206
11.5.2. Garantias funcionais do Judiciário (ou de órgãos)	1208
11.5.2.1. Garantias de independência dos órgãos judiciários	1208
11.5.2.1.1. Vitaliciedade	1208
11.5.2.1.2. Inamovibilidade	1210
11.5.2.1.3. Irredutibilidade de subsídios	1212
11.5.2.2. Garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários	1213
11.5.3. Prerrogativa de foro: o magistrado aposentado tem direito a foro especial por prerrogativa de função?	1214
11.6. Estrutura do Judiciário	1216
11.6.1. Órgãos de convergência e órgãos de superposição	1216
11.6.2. Justiças: comum e especial	1217
11.6.3. Competência penal versus competência civil	1218
11.6.4. Juizados Especiais: algumas particularidades	1219
11.6.4.1. Não cabimento de Recurso Especial para o STJ e o cabimento de Rcl	1219
11.6.4.2. Cabimento de RE para o STF	1221
11.6.4.3. Cabimento de HC e MS contra ato de juizado especial — superação da S. 690/STF	1222
11.6.4.4. Ação de indenização em razão do fumo: incompetência dos Juizados — complexidade da causa	1230
11.6.4.5. Juizados e a Lei Maria da Penha	1231
11.6.5. Organograma do Poder Judiciário ⁴⁴	1231

11.6.5. Organograma do Poder Judiciário ⁴⁴	1231
11.7. A REGRA DO “QUINTO CONSTITUCIONAL”	1232
11.8. Características gerais dos órgãos do Poder Judiciário	1235
11.8.1. Supremo Tribunal Federal (STF)	1235
11.8.1.1. STF — aspectos históricos ⁵²	1235
11.8.1.2. STF — regras gerais	1241
11.8.1.3. STF — destaques às novidades trazidas pela EC n. 45/2004 (“Reforma do Judiciário”)	1242
11.8.1.4. STF — procedimento para deliberação e encaminhamento de solicitações de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPR)	1247
11.8.2. Superior Tribunal de Justiça (STJ)	1248
11.8.3. Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Juízes Federais	1253
11.8.4. Tribunais e Juízes do Trabalho de acordo com a EC n. 24/99	1255
11.8.4.1. Tribunal Superior do Trabalho (TST)	1255
11.8.4.2. Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs)	1256
11.8.4.3. Juízes do trabalho — Varas do Trabalho	1257
11.8.4.4. Competências da Justiça do Trabalho	1257
11.8.4.5. O que aconteceu com os mandatos dos classistas em face da EC n. 24/99?	1263
11.8.5. Tribunais e Juízes Eleitorais	1263
11.8.5.1. Tribunal Superior Eleitoral (TSE)	1264
11.8.5.2. Tribunal Regional Eleitoral (TRE)	1264
11.8.5.3. Juízes Eleitorais	1265
11.8.5.4. Juntas Eleitorais	1266
11.8.6. Tribunais e Juízes Militares	1266
11.8.6.1. Superior Tribunal Militar (STM)	1267
11.8.6.2. Justiça Militar da União	1269
11.8.6.2.1. Regras gerais e Circunscrições Judiciárias Militares	1269
11.8.6.2.2. Conselhos de Justiça Militar	1270
11.8.6.2.3. Hierarquia militar (postos e graduações)	1273
11.8.6.2.4. Ministério Público Militar e Defensoria	1276

11.8.6.2.5. A Justiça Militar da União julga civil?	1277
11.8.6.2.6. E os crimes dolosos contra a vida?	1278
11.8.6.2.7. A Lei n. 9.099/95 (que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências) se aplica no âmbito da Justiça Militar?	1280
11.8.6.2.8. A Justiça Militar da União e a Reforma do Judiciário	1281
11.8.6.3. Justiça Militar dos Estados	1282
11.8.6.3.1. Atribuições	1282
11.8.6.3.2. Composição e competência	1283
11.8.6.3.3. Aplicação da pena de perda do posto e da patente (oficiais) e da graduação (praças): atribuição exclusiva do Tribunal competente ou possibilidade de ser imposta como pena acessória?	1286
11.8.6.3.4. Hierarquia militar estadual (postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar) ⁸⁵	1289
11.8.6.3.5. Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual (Justiça Militar Estadual)	1290
11.8.6.4. Justiça Militar do Distrito Federal	1291
11.8.7. Tribunais e Juízes dos Estados	1291
11.8.8. Varas Agrárias e os conflitos fundiários	1293
11.8.9. Justiça Estadual é competente para julgar crimes comuns entre silvícolas	1296
11.8.10. Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios	1297
11.9. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU PARA COMPOR ÓRGÃO JULGADOR DE TRIBUNAL	1298
11.10. mAGISTRATURA — teto de subsídio x teto de remuneração — PODER JUDICIÁRIO — caráter nacional E UNITÁRIO	1300
11.11. Da Justiça de Paz (art. 98, II)	1304
11.11.1. Regras gerais	1304
11.11.2. Os juízes de paz integram o Poder Judiciário?	1307
11.12. Dos precatórios	1308
11.12.1. Regras gerais	1308

11.12.1. Regras gerais	1308
11.12.2. Espécies de precatórios e exceção no caso das obrigações de pequeno valor	1310
11.12.3. Sistemática da “superpreferência” — art. 100, § 2.º (EC n. 62/2009)	1313
11.12.4. Compensação de precatório com débitos tributários — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF	1314
11.12.5. Utilização de precatórios para compra de imóveis públicos	1315
11.12.6. Atualização de valores de requisitórios de acordo com os índices da caderneta de poupança — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF	1315
11.12.7. Cessão dos créditos em precatórios a terceiros e a possibilidade de assunção de débitos diretamente pela União	1317
11.12.8. Regime especial para pagamento de crédito de precatórios — art. 100, § 15, da CF/88 e art. 97 do ADCT — inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Modulação dos efeitos da decisão — sobrevida ao regime especial por 5 exercícios financeiros a contar de 1.º.01.2016 (ADIs 4.357 e 4.425-QO, j. 25.03.2015)	1318
11.12.9. Regime especial para pagamento de crédito de precatórios e os parcelamentos anteriores introduzidos pelos arts. 33 e 78 do ADCT	1322
11.12.10. Débitos das entidades da administração indireta: precatórios?	1324
11.12.11. Intervenção federal ou estadual e não pagamento de precatórios	1326
11.13. Conselho Nacional de Justiça	1328
11.13.1. Aspectos gerais e composição do CNJ	1328
11.13.2. Aperfeiçoamento do CNJ: EC n. 61/2009	1330
11.13.3. Inexistência de regulamentação (critérios objetivos) para a indicação dos membros do CNJ	1332
11.13.4. O CNJ é constitucional?	1334
11.13.5. Atribuições do CNJ e o controle de suas decisões pelo STF (limites?)	1337
11.13.5.1. Regras gerais	1337
11.13.5.2. O CNJ não exerce função jurisdicional	1339

11.13.5.3. O CNJ tem atribuição para exercer o controle de constitucionalidade?	1340
11.13.5.4. STF: órgão de cúpula jurisdicional e órgão de cúpula administrativa, financeira e disciplinar (amplitude)	1341
11.13.5.5. O STF não deve ser considerado mera instância ordinária revisora das decisões administrativas do CNJ	1342
11.13.6. O CNJ tem controle da função jurisdicional do Judiciário?	1344
11.13.7. Corregedoria Nacional de Justiça e Ministro-Corregedor do CNJ	1344
11.13.8. O CNJ, no exercício de suas atribuições correccionais, atua originariamente (primariamente) e concorrentemente com as Corregedorias dos tribunais	1345
11.13.9. Prerrogativa de foro	1346
11.13.10. Outras regras sobre o CNJ	1347
11.14. Súmula vinculante	1348
11.14.1. Duas realidades: a morosidade da Justiça e as teses jurídicas repetitivas	1348
11.14.2. As “famílias” do direito	1348
11.14.3. Influência do stare decisis da família da common law	1350
11.14.4. Influência da Alemanha e da Áustria	1350
11.14.5. A influência do direito português	1351
11.14.6. A evolução do “direito sumular” no Brasil (fase colonial — influência do direito português)	1351
11.14.7. A evolução do “direito sumular” no Brasil (após a independência)	1352
11.14.8. Prenúncios da súmula vinculante em âmbito constitucional	1353
11.14.9. Prenúncios da súmula vinculante no âmbito do direito processual civil	1354
11.14.10. Os contornos da súmula vinculante na EC n. 45/2004	1354
11.14.11. As regras trazidas pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006 — súmula vinculante	1356
11.14.11.1. Competência	1357

11.14.11.2. Objeto	1357
11.14.11.3. Requisitos para a edição	1357
11.14.11.4. Legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante	1357
11.14.11.5. Procedimento	1358
11.14.11.6. Efeitos da súmula	1360
11.14.11.7. Modulação dos efeitos	1362
11.14.11.8. Revogação ou modificação da lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante	1363
11.14.11.9. Da reclamação	1363
11.14.11.10. Responsabilidade do administrador público	1364
11.14.11.11. Responsabilidade dos magistrados?	1364
11.14.12. As 53 súmulas vinculantes (a de número 30 com a publicação suspensa)	1366
11.14.13. Aspectos conclusivos	1373
11.15. Extinção dos Tribunais de Alçada	1375
11.15.1. Histórico nas Constituições	1375
11.15.2. O surgimento dos Tribunais de Alçada nos Estados	1376
11.15.3. A EC n. 45/2004	1377
11.16. Questões	1378
12 - FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA	1394
12.1. Noções introdutórias	1394
12.2. Ministério Público	1394
12.2.1. Histórico	1394
12.2.1.1. Origens remotas	1394
12.2.1.2. Constituição de 1824	1396
12.2.1.3. Constituição de 1891	1397
12.2.1.4. Constituição de 1934	1398
12.2.1.5. Constituição de 1937	1400
12.2.1.6. Constituição de 1946	1401
12.2.1.7. Constituição de 1967	1403
12.2.1.8. Emenda Constitucional n. 1/69	1403
12.2.1.9. Constituição de 1988	1404
12.2.2. Definição e investidura (“quarentena de entrada”)	1405

12.2.3. Organização do Ministério Público na CF/88 — art. 128, I e II, e MP Eleitoral	1406
12.2.3.1. Organização do Ministério Público da União e Estadual	1406
12.2.3.2. MP Eleitoral	1407
12.2.4. Chefe do Ministério Público	1409
12.2.4.1. Procurador-Geral da República	1409
12.2.4.2. Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	1411
12.2.4.3. Procurador-Geral do Trabalho	1413
12.2.4.4. Procurador-Geral da Justiça Militar	1413
12.2.4.5. Procurador-Geral Eleitoral	1414
12.2.4.6. Procurador Regional Eleitoral	1414
12.2.4.7. Novas perspectivas em relação à nomeação do PGR	1415
12.2.5. Princípios institucionais	1416
12.2.5.1. Regras gerais	1416
12.2.5.2. Legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual para o ajuizamento de reclamação no STF, sem que se exija a ratificação da inicial pelo PGR	1416
12.2.6. Princípio do promotor natural	1419
12.2.7. Garantias do Ministério Público	1425
12.2.7.1. Garantias institucionais	1425
12.2.7.1.1. Autonomia funcional	1425
12.2.7.1.2. Autonomia administrativa	1425
12.2.7.1.3. Autonomia financeira	1426
12.2.7.2. Garantias dos membros do Ministério Público	1426
12.2.7.2.1. Vitaliciedade	1426
12.2.7.2.2. Inamovibilidade	1427
12.2.7.2.3. Irredutibilidade de subsídios	1427
12.2.7.3. Impedimentos imputados aos membros do Ministério Público (vedações)	1427
12.2.7.4. Abrangência das garantias e impedimentos	1432
12.2.8. Funções institucionais do Ministério Público	1432
12.2.9. A teoria dos “poderes implícitos” e o poder de	1434

investigação criminal pelo MP	1434
12.2.10. Conselho Nacional do Ministério Público	1437
12.2.10.1. Regras gerais e composição	1437
12.2.10.2. Escolha dos membros do Ministério Público da União	1438
12.2.10.3. Escolha dos 3 membros do Ministério Público dos Estados	1438
12.2.10.4. A sabatina no Senado Federal e a falta de critérios para a indicação dos demais membros do Conselho que não os oriundos da carreira do Ministério Público	1439
12.2.10.5. Esquematização gráfica sobre a indicação dos membros do CNMP	1440
12.2.10.6. Corregedor Nacional	1441
12.2.10.7. Atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)	1442
12.2.10.8. Pode o CNMP fixar novo teto remuneratório dos membros e servidores do Ministério Público diferente do estabelecido na CF/88?	1443
12.2.10.9. O CNMP tem competência para realizar controle de constitucionalidade no exercício de suas atribuições?	1444
12.2.10.10. Outras regras	1445
12.2.11. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (art. 130)	1446
12.3. Advocacia pública	1448
12.3.1. A distorção corrigida pela EC n. 19/98	1448
12.3.2. O advogado público pode exercer a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo?	1449
12.3.3. Assessoramento, amplitude vinculativa dos pareceres jurídicos e a responsabilização dos advogados públicos	1452
12.3.4. Contempt of Court: a multa do art. 14, parágrafo único, do CPC/73 e os advogados públicos — ADI 2.652. CPC/2015 — avanço na linha da decisão do STF	1455
12.3.5. Pareceres e Súmula da Advocacia-Geral da União	1457
12.3.6. Advocacia-Geral da União	1458

12.3.6.2. Órgãos da Advocacia-Geral da União	1460
12.3.6.3. Advogado-Geral da União	1461
12.3.6.4. O caso particular do “direito de manifestação” do AGU no controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, § 3.º)	1462
12.3.6.5. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	1466
12.3.6.6. Procuradoria-Geral Federal	1467
12.3.6.7. Procuradoria-Geral do Banco Central	1467
12.3.6.8. A prerrogativa da intimação pessoal dos advogados públicos e a regra no CPC/2015	1467
12.3.6.9. A obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n. 10.910/2004, aplica-se ao rito dos Juizados Especiais Federais?	1468
12.3.6.10. Advogados públicos no âmbito da Administração Federal gozam de 30 ou de 60 dias de férias?	1469
12.3.7. Procuradoria-Geral dos Estados e do Distrito Federal	1472
12.3.7.1. Estrutura unitária	1472
12.3.7.2. Nomeação e destituição do Procurador-Geral pelo Governador	1474
12.3.7.3. Garantias e impedimentos dos Procuradores do Estado e do DF	1475
12.3.8. Procuradoria-Geral dos Municípios	1477
12.3.9. Advocacia pública e os honorários de sucumbência no CPC/2015	1477
12.4. Advocacia	1478
12.5. Estatuto da oab à luz da jurisprudência do stf	1479
12.5.1. ADIs 1.105 e 1.12763	1479
12.5.1.1. A exegese fixada pelo STF	1479
12.5.1.2. Quadro-resumo	1484
12.5.1.3. Sala de Estado-Maior	1485
12.5.2. ADIs 1.194, 2.522, 3.026, 3.168 e 3.541	1489
12.5.3. Constitucionalidade do Exame de Ordem: vitória para os bacharéis em direito e conquista da sociedade	1492

para os bacharéis em direito e conquista da sociedade	
12.5.4. Súmula Vinculante 5/STF x Súmula 343/STJ	1495
12.5.5. Súmula Vinculante 47/2015	1495
12.6. Defensoria Pública	1496
12.6.1. “Ondas renovatórias”	1496
12.6.2. Assistência jurídica integral e gratuita — aspectos gerais e evolução constitucional	1497
12.6.3. Regras gerais	1498
12.6.4. O fortalecimento da Defensoria Pública pela EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário), bem como pelas ECs ns. 69/2012 e 74/2013	1500
12.6.5. Autonomia da Defensoria Pública da União — DPU. Constitucionalidade da EC n. 74/2013. A pretensão formulada na ADI 5.296 (10.04.2015) mostra-se totalmente infundada	1502
12.6.6. As profundas alterações introduzidas pela EC n. 80/2014	1506
12.6.6.1. Visão topológica	1507
12.6.6.2. Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado	1508
12.6.6.3. Princípios institucionais	1508
12.6.6.4. Número de defensores públicos na unidade jurisdicional	1508
12.6.6.5. O defensor público, uma vez nomeado e tendo tomado posse, tem o dever de continuar inscrito nos quadros da OAB?	1510
12.6.7. Existe Defensoria Pública Municipal?	1512
12.6.8. Princípio do defensor público natural	1512
12.6.9. Algumas problemáticas já decididas pela jurisprudência do STF e do STJ	1513
12.6.9.1. A indispensabilidade do concurso público para ingresso na carreira	1513
12.6.9.2. Servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no “exercício regular” de suas funções tem direito à “assistência judiciária” do Estado? Essa atribuição pode ser destinada à Defensoria Pública Estadual?	1514

12.6.9.3. Prazo em dobro e intimação pessoal: prerrogativas da Defensoria Pública. A questão da regra do prazo em dobro para o processo penal. “Lei ainda constitucional”	1515
12.6.9.4. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para Procuradores do Estado no exercício da assistência judiciária, como foi o caso de São Paulo?	1516
12.6.9.5. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para os advogados dativos?	1516
12.6.9.6. As prerrogativas do prazo em dobro e intimação pessoal para a Defensoria Pública aplicam-se ao rito especial dos Juizados?	1518
12.6.9.7. Como ficou a prerrogativa do prazo em dobro e da intimação pessoal no CPC/2015?	1519
12.6.9.8. Defensor público pode exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais?	1520
12.6.9.9. Inconstitucionalidade progressiva — art. 68 do CPP — “lei ainda constitucional”	1520
12.6.9.10. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública?	1521
12.6.9.11. O Defensor Público pode receber honorários advocatícios? Como ficou no CPC/2015?	1524
12.6.9.12. O Defensor Público tem a garantia da vitaliciedade ou a da estabilidade?	1525
12.6.9.13. O Defensor Público tem a garantia da inamovibilidade?	1526
12.6.9.14. Remuneração	1526
12.6.9.15. O Defensor Público tem poder de requisição?	1527
12.6.9.16. A Defensoria Pública Estadual e a Distrital podem atuar nos Tribunais Superiores?	1528
12.6.9.17. É constitucional a imposição por ato normativo da obrigatoriedade de convênio a ser firmado entre a Defensoria Pública e a OAB, para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita?	1528
12.7. Questões99	1529
12.7.1. Ministério Público	1529

12.7.1. Ministério Público	1529
12.7.2. Advocacia	1534
12.7.3. Defensoria Pública	1536
12.7.4. Geral	1539
13 - DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS	1548
13.1. Noções introdutórias — Sistema constitucional das crises	1548
13.2. Estado de defesa	1549
13.2.1. Hipóteses de decretação do estado de defesa	1550
13.2.2. Procedimento e regras gerais	1550
13.2.3. Controle exercido sobre a decretação do estado de defesa ou sua prorrogação	1551
13.3. Estado de sítio	1552
13.3.1. Hipóteses de decretação do estado de sítio	1552
13.3.2. Procedimento e abrangência	1553
13.3.3. Medidas coercitivas	1554
13.3.4. Controle exercido sobre a decretação do estado de sítio	1555
13.4. Disposições comuns aos estados de defesa e de sítio	1556
13.5. quadro comparativo entre o estado de defesa e o estado de sítio	1556
13.6. Forças Armadas	1566
13.6.1. Regras gerais	1566
13.6.2. Novidades introduzidas pela EC n. 77/2014	1569
13.6.3. Habeas corpus e punições disciplinares militares	1569
13.6.4. Serviço militar obrigatório	1570
13.6.5. Leis de iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, I e II, “f”)	1570
13.6.6. As praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber abaixo do salário mínimo?	1571
13.6.7. Editais de concurso podem estabelecer limite de idade para o ingresso nas Forças Armadas?	1572
13.6.8. “Princípio da insignificância” e crimes militares: o caso concreto de posse de reduzida quantidade de substância entorpecente. Princípio da especialidade. Afastamento da	1574

13.6.9. Criação do Ministério da Defesa pela EC n. 23/99	1577
13.7. Segurança Pública	1578
13.7.1. Aspectos gerais	1578
13.7.2. Cooperação entre a União e os Estados-Membros e o DF e a Força Nacional de Segurança Pública	1581
13.7.3. BEPE — Batalhão Especial de Pronto Emprego	1583
13.7.4. UPPs — Unidades de Polícia Pacificadora (RJ)	1583
13.7.5. Polícias da União	1584
13.7.5.1 Polícia Federal (PF)	1584
13.7.5.2. Polícia Rodoviária Federal (PRF)	1586
13.7.5.3. Polícia Ferroviária Federal (PFF)	1587
13.7.6. Polícias dos Estados	1588
13.7.6.1. Polícia civil estadual	1589
13.7.6.2. Nos Municípios em que o Departamento de Polícia Civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia de carreira, o atendimento nas delegacias de polícia poderá ser realizado por subtenente ou sargento da polícia militar?	1589
13.7.6.3. Polícia judiciária dos Estados — discussão sobre a escolha do diretor-geral da Polícia Civil. Superação do entendimento firmado na ADI 132. Reconstrução jurisdicional da própria teoria do federalismo (ADI 3.062). Análise da ADI 3.038	1589
13.7.6.4. Polícia ostensiva ou preventiva dos Estados — PM e Corpo de Bombeiros Militares	1592
13.7.7. Polícias do Distrito Federal	1594
13.7.8. Polícias dos Territórios	1595
13.7.9. Policiais civis e militares: direito de greve (?) e anistia (?)	1599
13.7.9.1. Direito de greve?	1599
13.7.9.2. Lei poderá conceder anistia a policiais civis ou militares (PM e Corpo de Bombeiros) em relação a eventuais crimes praticados e infrações disciplinares conexas decorrentes de participação em movimentos reivindicatórios?	1601

13.7.10. Polícias dos Municípios	1606
13.7.11. Segurança viária. Carreira dos agentes de trânsito. EC n. 82/2014	1608
13.7.11.1. Tramitação da EC n. 82/2014	1608
13.7.11.2. A segurança viária é questão de saúde pública	1609
13.7.11.3. Tripé da segurança viária	1610
13.7.11.4. Segurança viária: questão a ser tratada de forma indissociável da segurança pública	1611
13.7.11.5. A carreira específica de agentes de trânsito	1611
13.8. Questões	1612
14 - DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	1625
14.1. Localização	1625
14.2. Evolução dos direitos fundamentais (“gerações” ou “dimensões” de direitos)	1625
14.2.1. Direitos fundamentais da 1. ^a dimensão	1626
14.2.2. Direitos fundamentais da 2. ^a dimensão	1627
14.2.3. Direitos fundamentais da 3. ^a dimensão	1628
14.2.4. Direitos fundamentais da 4. ^a dimensão	1629
14.2.5. Direitos fundamentais da 5. ^a dimensão	1630
14.3. Diferenciação entre direitos e garantias fundamentais	1630
14.4. Características dos direitos e garantias fundamentais	1631
14.5. Abrangência dos direitos e garantias fundamentais	1633
14.6. A APLICABILIDADE DAS NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	1634
14.7. A teoria dos quatro status de jellinek	1635
14.8. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais	1636
14.8.1. Aspectos gerais	1636
14.8.2. Teorias da eficácia indireta (mediata) ou direta (imediata)	1637
14.8.3. Eficácia “irradiante” dos direitos fundamentais	1638
14.8.4. Alguns precedentes	1638
14.8.5. Brevíssima conclusão	1639
14.9. dEVERES FUNDAMENTAIS	1640
14.10. Direitos individuais e coletivos	1641

14.10.1.1. Aspectos gerais	1641
14.10.1.2. Células-tronco embrionárias	1643
14.10.1.3. Interrupção de gravidez de feto anencefálico	1645
14.10.1.4. Eutanásia	1646
14.10.2. Princípio da igualdade (art. 5.º, caput, I)	1647
14.10.2.1. Aspectos gerais	1647
14.10.2.2. “Separate but equal” e “Treatment as an equal”	1648
14.10.2.3. Ações afirmativas — três importantes precedentes da Suprema Corte (Cotas Raciais, PROUNI e Lei Maria da Penha) e a Lei n. 12.990/2015	1649
14.10.2.4. Ações afirmativas — indicação de Ministros para o STF	1653
14.10.2.5. Princípio da congeneridade	1654
14.10.2.6. Foro da residência da mulher no CPC/73. Nova regra trazida pelo CPC/2015 (foro de domicílio do guardião de filho incapaz)	1655
14.10.2.7. Art. 384 da CLT: intervalo de 15 minutos para as mulheres antes de hora extra	1656
14.10.3. Princípio da legalidade (art. 5.º, II)	1657
14.10.4. Proibição da tortura (art. 5.º, III)	1658
14.10.5. Liberdade da manifestação de pensamento (art. 5.º, IV e V)	1659
14.10.5.1. Liberdade de expressão e a problemática do “hate speech”. “Posição de preferência” da liberdade de expressão. Interessante exemplo no âmbito da rede mundial de computadores (“marco civil da internet” — Lei n. 12.965/2014)	1661
14.10.5.2. Ainda a problemática do “hate speech” (discursos de incitação ao ódio). Liberdade de expressão e a prática do crime de racismo: precedente histórico na jurisprudência do STF — HC 82.424. A liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto	1663
14.10.5.3. Delação anônima	1665
14.10.5.4. “Marcha da maconha”	1666
14.10.6. Liberdade de consciência, crença e culto (art. 5.º, VI a VIII)	1668

14.10.6.1. Regras gerais	1668
14.10.6.2. Ensino religioso nas escolas	1670
14.10.6.3. Feriados religiosos	1671
14.10.6.4. Casamento perante autoridades religiosas	1671
14.10.6.5. Transfusão de sangue nas Testemunhas de Jeová	1671
14.10.6.6. Curandeirismo	1672
14.10.6.7. Crucifixos em repartições públicas	1673
14.10.6.8. Imunidade religiosa	1673
14.10.6.9. Guarda sabática	1674
14.10.6.10. A expressão “Deus seja louvado” nas cédulas de real	1675
14.10.6.11. Aspectos conclusivos	1676
14.10.7. Liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Indenização em caso de dano (art. 5.º, IX e X)	1676
14.10.8. Intimidade e vida privada e o sigilo bancário (art. 5.º, X)	1678
14.10.9. Inviolabilidade domiciliar (art. 5.º, XI)	1680
14.10.10. Sigilo de correspondência e comunicações (art. 5.º, XII)	1681
14.10.11. Liberdade de profissão (art. 5.º, XIII)	1684
14.10.12. Liberdade de informação (art. 5.º, XIV e XXXIII)	1686
14.10.13. Liberdade de locomoção (art. 5.º, XV e LXI)	1687
14.10.14. Direito de reunião (art. 5.º, XVI)	1688
14.10.15. Direito de associação (art. 5.º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI)	1688
14.10.16. Direito de propriedade (art. 5.º, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI)	1689
14.10.17. Direito de herança e estatuto sucessório (art. 5.º, XXX e XXXI)	1692
14.10.18. Propriedade intelectual (art. 5.º, XXVII, XXVIII e XXIX)	1693
14.10.19. Defesa do consumidor (art. 5.º, XXXII)	1693
14.10.20. Direito de petição e obtenção de certidões (art. 5.º, XXXIV)	1696

5.º, XXXV)	1699
14.10.22. Limites à retroatividade da lei (art. 5.º, XXXVI)	1703
14.10.23. Princípio do promotor natural (art. 5.º, LIII)	1706
14.10.24. Princípio do juiz natural ou legal (art. 5.º, XXXVII e LIII)	1706
14.10.25. Tribunal Penal Internacional — “TPI” (art. 5.º, § 4.º — EC n. 45/2004)	1708
14.10.26. Federalização dos crimes contra direitos humanos (art. 109, V-A e § 5.º — EC n. 45/2004) — Incidente de deslocamento de competência — IDC	1711
14.10.27. Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII)	1717
14.10.28. Segurança jurídica em matéria criminal (art. 5.º, XXXIX a LXVII) e a teoria dos mandados expressos de criminalização à luz dos direitos fundamentais	1718
14.10.28.1. Legalidade e anterioridade da lei penal incriminadora. Irretroatividade da lei penal “in pejus” (art. 5.º, XXXIX e XL)	1719
14.10.28.2. Práticas discriminatórias, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e crimes inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5.º, XLI a XLIV)	1723
14.10.28.3. Regras constitucionais sobre as penas (art. 5.º, XLV a XLVIII)	1725
14.10.28.4. Direitos assegurados aos presos (art. 5.º, XLIX, L, LXII, LXIII e LXIV)	1727
14.10.28.5. Regras sobre extradição (art. 5.º, LI e LII)	1727
14.10.28.6. Presunção de inocência (não culpabilidade) (art. 5.º, LVII)	1728
14.10.28.7. Regras sobre a prisão (art. 5.º, LXI, LXV, LXVI, LXVII)	1729
14.10.28.8. Identificação criminal (art. 5.º, LVIII)	1730
14.10.28.9. Ação penal privada subsidiária da pública (art. 5.º, LIX)	1731
14.10.29. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV)	1732
14.10.29.1. Aspectos gerais	1732
14.10.29.2. Interrogatório por videoconferência (on-line)	1733

14.10.29.3. Transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima	1737
14.10.29.4. Art. 98 do antigo Regimento Interno do CNJ: necessidade de intimação pessoal de terceiros que demonstrem interesse jurídico nos procedimentos de controle administrativo (PCAs). Correção no novo RI	1738
14.10.30. Devido processo legal substantivo ou material (arts. 5.o, LV, e 3.o, I)	1739
14.10.31. Provas ilícitas (art. 5.º, LVI)	1740
14.10.32. Publicidade dos atos processuais (e dever de motivação das decisões judiciais) (art. 5.º, LX). Perspectivas do CPC/2015	1740
14.10.33. Assistência jurídica integral e gratuita (art. 5.º, LXXIV)	1742
14.10.34. Erro judiciário (art. 5.º, LXXV)	1743
14.10.35. Gratuidade das certidões de nascimento e de óbito (art. 5.º, LXXVI)	1744
14.10.36. Gratuidade nas ações de habeas corpus e habeas data (art. 5.º, LXXVII)	1746
14.10.37. Celeridade processual (art. 5.º, LXXVIII)	1747
14.10.37.1. Aspectos gerais	1747
14.10.37.2. Celeridade do processo e crimes praticados contra os idosos	1749
14.10.37.3. Leis infraconstitucionais decorrentes da EC n. 45/2004 (“Reforma do Poder Judiciário”)130 no sentido de “racionalização da prestação jurisdicional” — frutos dos “Pactos Republicanos”	1750
14.11. Remédios constitucionais	1755
14.11.1. Os remédios constitucionais nas Constituições brasileiras — quadro esquematizado	1755
14.11.2. Habeas corpus (art. 5.º, LXVIII)132	1757
14.11.2.1. Regras gerais	1757
14.11.2.2. Esquematização da evolução histórica do “HC” no constitucionalismo brasileiro	1758
14.11.2.3. Competência	1761
14.11.2.4. Espécies	1762

14.11.2.6. “Habeas corpus” impetrado em face de ato da “Turma Recursal” — competência do TJ — superada a S. 690/STF	1763
14.11.3. Mandado de segurança (art. 5.º, LXIX)	1763
14.11.3.1. Introdução	1763
14.11.3.2. Esquematização da evolução histórica do “MS” no constitucionalismo brasileiro ¹³⁸	1764
14.11.3.3. Abrangência	1765
14.11.3.4. Direito líquido e certo	1766
14.11.3.5. Ilegalidade ou abuso de poder	1766
14.11.3.6. Legitimidade ativa e passiva	1767
14.11.3.7. Competência	1767
14.11.3.8. Algumas outras observações	1768
14.11.4. Mandado de segurança coletivo (art. 5.º, LXX)	1769
14.11.4.1. Regras gerais	1769
14.11.4.2. Objeto, legitimidade ativa e objetivos	1770
14.11.4.2.1. Objeto	1770
14.11.4.2.2. Legitimidade ativa	1770
14.11.4.2.2.1. Partidos políticos	1771
14.11.4.2.2.2. Organizações sindicais, entidades de classe e associações	1771
14.11.4.2.3. Objetivos	1772
14.11.5. Mandado de injunção (art. 5.º, LXXI)	1773
14.11.5.1. Aspectos gerais	1773
14.11.5.2. Legitimidade ativa e passiva	1774
14.11.5.3. Competência	1775
14.11.5.4. Procedimento e efeitos da decisão	1776
14.11.5.5. Perspectivas de um “ativismo judicial”	1780
14.11.6. Habeas data (art. 5.º, LXXII)	1780
14.11.6.1. Aspectos gerais	1780
14.11.6.2. Legitimidade ativa e passiva	1781
14.11.6.3. Procedimento	1782
14.11.6.4. Competência	1782
14.11.7. Ação popular (art. 5.º, LXXIII)	1783

14.11.7.1. Aspectos gerais	1783
14.11.7.2. Esquematização da evolução histórica da “ação popular” no constitucionalismo brasileiro	1784
14.11.7.3. Requisitos	1785
14.11.7.4. Legitimidade ativa e passiva	1786
14.11.7.5. Competência	1787
14.11.7.5.1. Regra geral — juízo de primeiro grau	1787
14.11.7.5.2. SEBRAE — competência da Justiça comum	1788
14.11.7.5.3. Ação popular contra o CNMP — incompetência do STF	1788
14.11.7.5.4. Incompetência originária do STF e indicação do órgão competente	1789
14.11.7.6. Outras regras	1791
14.12. Questões	1791
14.12.1. Direitos fundamentais	1791
14.12.2. Remédios constitucionais	1801
15 - DIREITOS SOCIAIS	1811
15.1. ASPECTOS GERAIS	1811
15.2. BREVES COMENTÁRIOS AOS DIREITOS SOCIAIS	1812
15.2.1. Direito à educação	1812
15.2.2. Direito à saúde	1814
15.2.3. Direito à alimentação	1814
15.2.4. Direito ao trabalho	1815
15.2.5. Direito à moradia	1815
15.2.6. Direito ao lazer	1817
15.2.7. Direito à segurança	1817
15.2.8. Direito à previdência social	1817
15.2.9. Proteção à maternidade e à infância	1818
15.2.10. Assistência aos desamparados	1819
15.3. “PEC DA FELICIDADE” — pec n. 513/2010-CD e PEC n. 19/2010-SF	1820
15.4. DIREITOS RELATIVOS AOS TRABALHADORES ⁴	1821
15.4.1. Direitos sociais individuais dos trabalhadores	1822

a 11)	1829
15.4.2.1. Direito de associação profissional ou sindical	1829
15.4.2.2. Direito de greve	1831
15.4.2.3. Direito de substituição processual	1831
15.4.2.4. Direito de participação	1832
15.4.2.5. Direito de representação classista	1832
15.5. “METODOLOGIA FUZZY” E “CAMALEÕES NORMATIVOS” NA PROBLEMÁTICA DOS DIREITOS SOCIAIS, CULTURAIS E ECONÔMICOS (CANOTILHO) ⁸	1832
15.5.1. Princípio do não retrocesso social ou da proibição da evolução reacionária. Interpretação a ser dada à EC n. 86/2015 (fruto da “PEC do Orçamento Impositivo”)	1834
15.5.2. Mínimo existencial: concretização dos direitos sociais e a implementação de políticas públicas	1836
15.6. QUESTÕES	1840
16 - NACIONALIDADE	1849
16.1. Conceito	1849
16.1.1. Definições correlatas	1849
16.2. Espécies de nacionalidade e critérios para a sua aquisição	1850
16.3. Brasileiro nato	1851
16.4. Brasileiro naturalizado	1853
16.4.1. Noções introdutórias: procedimento	1853
16.4.2. Naturalização ordinária	1854
16.4.3. Naturalização extraordinária ou quinquenária	1854
16.4.4. Radicação precoce e conclusão de curso superior?	1855
16.5. QUASE NACIONALIDADE — PORTUGUESES — ART. 12, § 1.º — reciprocidade	1856
16.6. A lei poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados?	1857
16.6.1. Regra geral	1857
16.6.2. Hipóteses taxativas de exceção à regra geral	1857
16.6.2.1. Extradicação	1857
16.6.2.1.1. Extradicação ativa	1858
16.6.2.1.2. Extradicação passiva: brasileiro nato x brasileiro naturalizado	1859

brasileiro naturalizado	
16.6.2.1.3. Extradicação passiva: regras procedimentais	1861
16.6.2.1.4. Extradicação passiva: vedações legais	1864
16.6.2.1.5. Extradicação passiva: e se o extraditando for casado com brasileira ou tiver filho brasileiro? Haverá óbice, por esse motivo, ao pedido de extradição?	1865
16.6.2.1.6. Extradicação passiva: entendendo o STF pela procedência do pedido de extradição, o Presidente da República será obrigado a extraditar o requisitado?	1866
16.6.2.1.7. Expulsão	1870
16.6.2.1.8. Deportação	1872
16.6.2.1.9. Banimento: existe expulsão ou banimento de brasileiros?	1873
16.6.2.1.10. Asilo político e refúgio (direito de permanecer no Brasil)	1873
16.6.2.2. Cargos privativos de brasileiros natos	1875
16.6.2.3. Atividade nociva ao interesse nacional	1875
16.6.2.4. Conselho da República	1876
16.6.2.5. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens	1876
16.7. Perda da nacionalidade	1877
16.7.1. Hipóteses de perda da nacionalidade	1877
16.7.1.1. Cancelamento da naturalização	1877
16.7.1.2. Aquisição de outra nacionalidade	1879
16.8. Reaquisição da nacionalidade brasileira perdida	1879
16.9. Questões	1880
17 - DIREITOS POLÍTICOS	1891
17.1. Noções introdutórias	1891
17.1.1. Democracia semidireta ou participativa	1891
17.1.2. Plebiscito versus referendo: experiências na história brasileira	1893
17.1.2.1. Referendo para manutenção ou não do regime parlamentarista (1963)	1893

17.1.2.2. Plebiscito para a escolha entre a forma (república ou monarquia constitucional) e sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) (1993)	1894
17.1.2.3. Referendo para a manifestação do eleitorado sobre a manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional (2005)	1895
17.1.2.4. Referendo no Estado do Acre para decidir sobre o fuso horário (2010)	1898
17.1.2.5. Plebiscitos no Estado do Pará para decidir sobre a formação dos Estados do Carajás e do Tapajós (2011)	1898
17.1.3. O resultado do plebiscito ou do referendo pode ser modificado por lei ou emenda à Constituição?	1899
17.1.4. Quadro comparativo: plebiscito versus referendo	1899
17.1.5. Outros institutos de democracia semidireta ou participativa: recall e veto popular	1901
17.2. Soberania popular, nacionalidade, cidadania, sufrágio, voto e escrutínio	1902
17.3. Direito político positivo (direito de sufrágio)	1902
17.3.1. Capacidade eleitoral ativa	1903
17.3.2. Capacidade eleitoral passiva	1905
17.3.2.1. Condições de elegibilidade	1906
17.4. Direitos políticos negativos	1906
17.4.1. Inelegibilidades	1907
17.4.1.1. Inelegibilidades absolutas	1907
17.4.1.2. Inelegibilidades relativas	1908
17.4.1.2.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida (por motivos funcionais)	1908
17.4.1.2.1.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida para um terceiro mandato sucessivo	1908
17.4.1.2.1.2. A figura do denominado “prefeito itinerante” ou “prefeito profissional”	1910
17.4.1.2.1.3. Inelegibilidade relativa em razão da função para concorrer a outros cargos	1911
17.4.1.2.2. Inelegibilidade relativa em razão do parentesco	1912

17.4.1.2.3. Militares	1915
17.4.1.2.4. Inelegibilidades previstas em lei complementar	1916
17.4.2. Candidatos com “ficha suja”: inelegibilidade?	1918
17.4.3. Privação dos direitos políticos — perda e suspensão	1923
17.4.3.1. Perda dos direitos políticos (arts. 15, I e IV, e 12, § 4.º, II, da CF/88)	1923
17.4.3.2. Suspensão dos direitos políticos (arts. 15, II, III e V, e 55, II, e § 1.º, da CF/88; art. 17.3 do Dec. n. 3.927/2001 c/c o art. 1.º, I, “b”, da LC n. 64/90)	1924
17.4.4. Reaquisição dos direitos políticos perdidos ou suspensos	1925
17.5. Servidor público e exercício do mandato eletivo	1926
17.6. Questões	1926
18 - PARTIDOS POLÍTICOS E O FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS	1940
18.1. Conceito	1940
18.2. Regras constitucionais	1940
18.3. Inconstitucionalidade da cláusula de barreira — proteção constitucional às minorias	1943
18.4. O princípio da verticalização das coligações partidárias e a EC n. 52/2006	1944
18.4.1. Primeiro momento — a consagração da regra da verticalização das coligações partidárias pelo TSE	1944
18.4.2. Ataques à regra da verticalização das coligações partidárias fixada pelo TSE	1946
18.4.3. Ataques à regra da EC n. 52/2006, que expressamente acabou com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Mantida a verticalização para as eleições de 2006 (princípio da anualidade — art. 16 da CF). A EC n. 52/2006 entrou em vigor na data de sua publicação, mas somente poderá ser aplicada às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência	1949
18.5. fidelidade partidária	1952
18.6. a vaga decorrente do licenciamento de titulares de mandato	

parlamentar deve ser ocupada pelos suplentes das coligações OU dos partidos?	1955
18.7. FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS — ADI 4.650	1957
18.8. QUESTÕES	1959
19 - ORDEM SOCIAL	1965
19.1. ASPECTOS GERAIS	1965
19.1.1. Valores da ordem social: base e objetivo	1965
19.1.2. Conteúdo da ordem social	1966
19.2. SEGURIDADE SOCIAL	1967
19.2.1. Princípios orientadores da organização da seguridade social	1967
19.2.2. Financiamento da seguridade social	1967
19.2.3. Competência discriminada (lei ordinária) e competência residual (lei complementar)	1969
19.2.4. Inconstitucionalidade do art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 9.718/98 (PIS/PASEP e COFINS). EC n. 20/98 — impossibilidade do fenômeno da “constitucionalidade superveniente”	1970
19.2.5. Cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para sociedades civis de profissões regulamentadas	1972
19.2.5.1. Inexistência de hierarquia entre LC e LO	1972
19.2.5.2. A questão da modulação dos efeitos da decisão pelo STF	1974
19.3. EDUCAÇÃO — FUNDEB — EC N. 53/2006	1976
19.3.1. Aspectos gerais	1976
19.3.2. Quadro esquematizado da educação escolar	1977
19.3.3. Regras gerais do fundo	1977
19.3.4. Fim (progressivo) da DRU para a educação e as ECs ns. 59/2009 e 68/2011	1979
19.4. CULTURA	1981
19.4.1. Plano Nacional de Cultura (EC n. 48/2005)	1982
19.4.2. Sistema Nacional de Cultura (EC n. 71/2012)	1984
19.5. DESPORTO	1985
19.5.1. Desporto em sentido amplo	1986

19.5.1. Desporto em sentido amplo	1986
19.5.2. Modalidades de desporto	1986
19.5.3. Papel do Estado e das entidades dirigentes e associações na promoção do desporto	1987
19.5.4. Destinação dos recursos públicos para o desporto	1988
19.5.5. Manifestações desportivas de “criação nacional”	1988
19.5.6. Justiça Desportiva	1989
19.5.6.1. Regras gerais, natureza jurídica e composição	1989
19.5.6.2. Instância administrativa de curso forçado: exceção ao princípio do acesso incondicionado ao Poder Judiciário. Necessidade de esgotamento das vias administrativas	1990
19.5.6.3. Questões trabalhistas: competência da Justiça do Trabalho	1991
19.5.6.4. Vedação do exercício de funções na Justiça Desportiva por integrantes do Poder Judiciário	1991
19.5.7. Bingos	1993
19.6. CIÊNCIA, TECNOLOGIA e inovação (EC n. 85/2015)	1994
19.6.1. Perspectivas introduzidas pela EC n. 85/2015	1994
19.6.2. O papel do Estado	1994
19.6.3. Modalidades de pesquisa e o tratamento prioritário do Estado	1996
19.6.4. Apoio e incentivo do Estado	1996
19.6.5. Estado Social de Direito: concepção social do mercado	1997
19.6.6. O destaque para a biotecnologia	1998
19.7. COMUNICAÇÃO SOCIAL	1999
19.7.1. Princípios orientadores da comunicação social	2000
19.7.2. Princípios a orientar a produção e a programação das emissoras de rádio e TV	2003
19.7.3. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens	2004
19.7.4. Serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (TV)	2006
19.7.4.1. Diferenciação entre os serviços de telecomunicação e de radiodifusão (EC n. 8/95)	2006

19.7.4.2. Concessão, permissão e autorização	2008
19.7.4.3. Prazo da concessão ou permissão e da autorização	2009
19.7.4.4. Outorga e renovação (da concessão ou permissão e da autorização)	2009
19.7.4.5. Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T): consignação de mais um canal de radiofrequência às concessionárias e “autorizadas” dos serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens, sem apreciação do Congresso Nacional	2011
19.7.5. Conselho de Comunicação Social: órgão auxiliar do CN	2012
19.7.6. Direito de antena	2012
19.7.7. Lei de Imprensa — ADPF 130	2013
19.7.8. “Lei Eleitoral sobre o Humor”	2014
19.8. MEIO AMBIENTE	2015
19.8.1. Conceito de meio ambiente	2015
19.8.2. Aspectos do meio ambiente	2016
19.8.3. Direitos humanos, direito ao desenvolvimento e direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações	2017
19.8.3.1. A problemática	2017
19.8.3.2. Sustentabilidade: solução para a problemática	2018
19.8.4. A proteção ambiental no constitucionalismo brasileiro	2019
19.8.5. Natureza jurídica do meio ambiente e a justiça distributiva entre as presentes e futuras gerações	2022
19.8.6. Incumbência do Poder Público	2022
19.8.7. Crueldade contra animais?	2023
19.8.7.1. Farra do boi	2024
19.8.7.2. Rinhas ou brigas de galo	2025
19.8.7.3. Rodeios de animais, vaquejada, “calf roping” e “team roping” (laçada dupla)	2025
19.8.7.4. Animais em circo	2027
19.8.7.4.1. A origem do circo — breve nota ⁴⁴	2027
19.8.7.4.2. O adestramento de animais em circos	2027

19.8.7.4.3. O fim dos animais em circos significaria o fim da cultura circense?	2028
19.8.8. Importação de pneus usados — ADPF 101	2029
19.8.9. Exploração de recursos minerais	2030
19.8.10. Responsabilidade por danos ambientais	2030
19.8.11. Ecossistemas especialmente protegidos e erigidos à categoria de patrimônio nacional	2031
19.8.12. Os “Soldados da Borracha” e a EC n. 78/2014	2032
19.8.13. Terras devolutas	2033
19.8.13.1. Classificação dos bens públicos: as terras devolutas enquanto bens dominicais	2033
19.8.13.2. Titularidade	2034
19.8.13.3. Terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado necessárias à proteção dos ecossistemas naturais — indisponibilidade	2035
19.8.14. Localização das usinas nucleares: necessidade de lei federal	2036
19.9. FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE, jovem E IDOSO	2036
19.9.1. Família: conceito de entidade familiar	2036
19.9.2. União homoafetiva (união estável entre pessoas do mesmo sexo)	2037
19.9.3. Transexualidade	2040
19.9.4. A união estável pode ser reconhecida em relação a uma menor de 14 anos estuprada que veio a se casar com o agressor, para efeitos de extinção de punibilidade quando era admitida (antes da revogação do art. 107, VII, do CP)?	2043
19.9.5. Família: assistência e proteção contra a violência doméstica. As particularidades da denominada Lei Maria da Penha (ADC 19 e ADI 4.424)	2044
19.9.5.1. Lei Maria da Penha: instrumento de proteção efetiva dos direitos fundamentais	2045
19.9.5.2. Não aplicação da Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)	2046
19.9.5.3. Constitucionalidade das regras até que sejam estruturados os “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”	2046

violência doméstica e familiar contra a mulher: ação penal pública incondicionada	2047
19.9.6. Casamento: regras gerais; gratuidade da celebração; efeito civil; liberdade de crença (centro espírita, candomblé, umbanda etc.)	2048
19.9.7. Divórcio: forma de dissolução do casamento civil à luz da EC n. 66/2010	2049
19.9.8. Liberdade para o planejamento familiar: dignidade da pessoa humana e paternidade responsável	2052
19.9.9. Criança, adolescente e jovem (EC n. 65/2010)	2053
19.9.10. Criança, adolescente e jovem: proteção especial	2056
19.9.11. Alienação parental	2057
19.9.12. Adoção	2058
19.9.12.1. Regras gerais sobre adoção	2058
19.9.12.2. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6.º. Posição do STF na AR 1.811	2059
19.9.12.3. Adoção internacional	2060
19.9.12.4. Adoção por casal homoafetivo ou transexual	2061
19.9.13. Direito de ação de investigação de paternidade: a problemática da submissão coercitiva ao exame de DNA	2062
19.9.14. Portadores de deficiência	2064
19.9.15. Inimputabilidade penal	2066
19.9.16. Dever de reciprocidade entre pais e filhos	2067
19.9.17. Idosos	2067
19.9.17.1. Princípios da solidariedade e proteção à luz da “reserva do possível”	2067
19.9.17.2. Idoso e transporte público: “constitucionalismo fraternal” ou “altruístico” — “ações distributivistas e solidárias” — “direito fraternal”	2068
19.9.17.3. Celeridade do processo e crimes praticados contra os idosos	2069
19.10. ÍNDIOS	2070
19.10.1. Os índios no constitucionalismo brasileiro	2070
19.10.2. Proteção das “minorias nacionais” e a importância da “terra”	2070

da “terra”	
19.10.3. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios	2072
19.10.3.1. Bens da União. Terras destinadas à posse permanente dos índios: bens públicos de uso especial	2072
19.10.3.2. Conceito	2074
19.10.3.3. Nulidade e extinção dos atos que atentem contra as “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”	2074
19.10.4. Indigenato: fonte para o direito dos índios sobre as suas terras	2075
19.10.5. Usufruto exclusivo dos índios e a mineração em terras indígenas	2076
19.10.6. Regras constitucionais para a remoção dos grupos indígenas	2077
19.10.7. Demarcação das terras indígenas	2078
19.10.7.1. Aspectos gerais	2078
19.10.7.2. Raposa Serra do Sol	2080
19.10.8. Defesa judicial dos direitos e interesses dos índios	2083
19.10.8.1. Legitimidade ativa: índios, comunidades, organizações e o MP (Federal ou Estadual)	2083
19.10.8.2. Competência: Justiça Federal x Justiça Estadual	2084
19.10.9. Educação nas comunidades indígenas	2085
19.10.10. Infanticídio indígena	2087
19.11. QUESTÕES	2089
20 - ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA	2105
20.1. PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA	2105
20.1.1. Evolução do Estado e a Ordem Econômica	2105
20.1.2. Separação da Ordem Econômica e da Ordem Social	2107
20.1.3. Meios de atuação do Estado	2107
20.1.4. Princípios da Ordem Econômica	2108
20.1.4.1. Soberania nacional	2108
20.1.4.2. Propriedade privada e sua função social	2109
20.1.4.3. Livre concorrência	2109
20.1.4.4. Defesa do consumidor	2110
20.1.4.5. Defesa do meio ambiente	2111
20.1.4.6. Redução das desigualdades regionais e sociais	2111

20.1.4.7. Busca do pleno emprego	2112
20.1.4.8. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte	2112
20.2. MONOPÓLIO DOS CORREIOS	2112
20.3. QUEBRA DO MONOPÓLIO DA UNIÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS PARA A PESQUISA E USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, BEM COMO SOBRE A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA (EC N. 49/2006)	2117
20.4. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	2119
20.5. QUESTÕES	2120
21 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	2126
21.1. justificativas iniciais	2126
21.2. REPÚBLICA	2127
21.3. federação	2127
21.4. estado democrático de direito	2128
21.4.1. Aspectos gerais	2128
21.4.2. A Lei da Anistia, a ADPF 153 e a decisão da “Corte Interamericana de Direitos Humanos”	2129
21.5. SEPARAÇÃO DE “PODERES”	2132
21.6. Fundamentos da República Federativa do Brasil	2132
21.7. objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil	2133
21.8. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais	2134
21.8.1. Art. 4.º, CF/88	2134
21.8.2. MERCOSUL	2135
21.8.3. MERCOSUL — evolução do Sistema de Solução de Controvérsias. Tribunal Permanente de Revisão (TPR)	2138
21.9. Questões	2139
22 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OUTROS TEMAS	2148
22.1. EXPLICITAÇÃO DA PROPOSTA	2148
22.2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2148

22.2.1. Princípio da legalidade	2149
22.2.2. Princípio da impessoalidade	2151
22.2.2.1. A questão específica das vagas previstas em edital e o direito subjetivo à nomeação: princípio da confiança	2153
22.2.2.2. IBGE: contratação temporária, sem concurso, para demandas sazonais de pesquisa	2156
22.2.2.3. Contratação pela administração pública, de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público (EC n. 51/2006)	2156
22.2.3. Princípio da moralidade administrativa	2158
22.2.4. Princípio da publicidade	2158
22.2.5. Princípio da eficiência	2159
22.2.6. Nepotismo	2159
22.3. “PEC PARALELA DA PREVIDÊNCIA” (EC N. 47/2005)	2161
22.3.1. Notas introdutórias	2161
22.3.2. Teto do funcionalismo (art. 37, §§ 11 e 12)	2162
22.3.2.1. Regras gerais	2162
22.3.2.2. Importantes questões já decididas pelo STF	2166
22.3.3. Aposentadorias especiais (arts. 40, § 4.º, I, II e III, e 201, § 1.º)	2173
22.3.4. Aumento da faixa de isenção de contribuição previdenciária para os servidores inativos e os pensionistas que sejam, nos termos da lei, portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21)	2175
22.3.5. Ampliação das hipóteses de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas das contribuições sociais para o financiamento da seguridade social (art. 195, § 9.º)	2175
22.3.6. Ampliação do sistema especial de inclusão previdenciária (art. 201, §§ 12 e 13)	2176
22.3.7. Paridade plena entre ativos e inativos (arts. 2.º e 5.º da EC n. 47/2005)	2177
22.3.8. Regra geral de transição (art. 3.º da EC n. 47/2005)	2178
22.3.9. Vigência da EC n. 47/2005 (art. 6.º)	2179
22.4. EC N. 55/2007	2179

22.5. “PEC DOS AGENTES DE SAÚDE” — EC N. 63/2010	2179
22.6. EC N. 70/2012	2180
22.7. EC N. 75/2013	2181
22.8. EC N. 84/2014	2181
REFERÊNCIAS	2182